

Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler

Prof. Dr. İzzet Özgenç
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi

Türk Ceza Hukuku

Genel Hükümler

- ❖ Ceza Hukukuna Giriş
- ❖ Suç Teorisi
- ❖ Yaptırım Teorisi
- ❖ Milletlerarası Ceza Hukuku

Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş
20. Bası

SEÇKİN | Hukuk

Ankara 2024

CEZA HUKUKU VE ADLÎ BİLİMLER VAKFI, Yayın No 2.



Akademik ve Mesleki Yayınlar

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler İzzet ÖZGENÇ

SEÇKİN | Hukuk
No: 754

ISBN 978-975-02-9439-6

Yirminci Bası: Eylül 2024

Sayfa Tasarımı:
Ayşegül GENÇ KEMEÇ

Kapak Tasarımı:
Seçkin Yayıncılık

1264 Sayfa, 16x23,5 cm.

1. Ceza Hukukunun Fonksiyonları
2. Türk Ceza Hukukunun Kaynakları
3. Suçun Yapısal Unsurları
4. Kusurluluk
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
6. Cezalar
7. Güvenlik Tedbirleri
8. Milletlerarası Ceza Hukuku

© Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

Satış ve Dağıtım:

Yayınevi Merkezi

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sokak No: 13 Çankaya/ANKARA
Tel: 0-312-435 30 30 – Faks: 0-312-435 24 72 – seckin@seckin.com.tr

İstanbul Çağlayan Adliyesi Şubesi

D Blok 2. Bodrum Kat No: 5
Çağlayan
Tel: (212) 240 00 15
Faks: (212) 240 00 15
caglayan@seckin.com.tr

İstanbul Kartal Adliyesi Şubesi

C Blok Zemin Kat No: 29 Kartal
Tel: (216) 303 11 23
Faks: (216) 303 11 23
kartalsube@seckin.com.tr

İstanbul Şişli Şubesi

Abide-i Hürriyet Cad.
No: 183/A Şişli
Tel: (212) 234 34 77
Faks: (212) 231 24 69
sislisube@seckin.com.tr

Ankara Sıhhiye Şubesi

Strazburg Cad. 23/B Sıhhiye
Tel: (312) 230 52 62
Faks: (312) 230 52 62
ankarasube@seckin.com.tr

Web Sitesi: www.seckin.com.tr

Seçkin Yayıncılık Sertifika No: 45644

Baskı:

Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti. – Sertifika No: 46586
İVOGSAN 1518 Sok. Mat-Sit İşmerkezi No: 2/40 Yenimahalle /ANKARA - Tel: (0-312) 395 21 10

Adalet, yakınlarının ve hatta kendisinin aleyhine de olsa, kişinin bir vakiya ilişkin gerçekliğin, hakikatin ortaya çıkmasına katkı sağlamasıdır. (Nisa Suresi, Ayet 135)

Geçmişte yaşanan bazı olaylar veya herhangi bir nedenle ortaya çıkan öfke, kin ve nefret duyguları, adaletsiz davranmaya ve haksız kararlar almaya yol açmamalıdır (Maide Suresi, Ayet 8).

Kişi, sadece kendi yaptıklarından dolayı sorumlu tutulmalıdır. **Ceza sorumluluğu şahsîdir**. Bir başkasının fiilinden dolayı sorumluluk yoktur (Necm Suresi, Ayet 37; En'am Suresi, Ayet 164; Fatır Suresi, Ayet 18; İsra Suresi, Ayet 15).

Kıyas, **suçun ağırlığına göre ceza** vermektir. **Suç ile ceza arasında oranın olması, cezanın ölçülü olması** (Rahman Suresi, Ayet 9), kıyası ifade etmektedir. Toplum barışının tesisi için, uygulanan yaptırım, kamu vicdanını tatmin etmelidir.

Adalet, aynı zamanda kişinin işlediği haksızlık dolayısıyla etkin pişmanlık göstermesini, sebebiyet verdiği mağduriyetin mümkün olduğunca giderilmesini sağlamayı gerekli kılmaktadır.

Ancak adalet, acıma duygusunun ötelenmesi sonucunu doğurmamalıdır. Acıma duygusu ve bağışlama, adalete ön gelen bir erdemdir (Bakara Suresi, Ayet 178, 179; Maide Suresi, Ayet 45; İsra Suresi, Ayet 33).

Bu itibarla bağışlama, kişinin gerçekleştirdiği haksızlıktan, işlediği suçlardan dolayı etkin pişmanlık duyup duymamasına, bu yanlışlıkların ve haksızlıkların etkilerini gidermeye yönelik olarak ve tam bir samimiyetle çaba gösterip göstermemesine bağlı olmalıdır.

Yirminci Basiya İlişkin Önsöz

Kitabın yirminci basısında, Yargıtay içtihatlarıyla yeni gelişen uygulamamız mümkün olduğunca gözönünde bulundurulmuş ve mevzuatta yapılan değişiklikler çerçevesinde özellikle infazla ilgili açıklamalar, güncellenmiştir.

Keza, kitap içeriğindeki ihmalî suçlara ilişkin açıklamalar büyük ölçüde yenilenmiş ve geliştirilmiştir.

Eserde, yeni TCK hükümlerinin uygulanmasına ilişkin **Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun güncel Kararlarının** irdelenmesine, büyük yer verilmiştir.

Kitabın son basısından itibaren yeni basısı yapılabildiği sürece ceza hukuku alanında özellikle Yargıtay uygulamaları itibarıyla meydana gelen gelişmelere ilişkin değerlendirmelerim, güncel bir şekilde **izzetozgenc.com** internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu değerlendirmeler, bilahare kitabın yeni basısına aktarılmaktadır.

Esere yönelik eleştirilerin şahsıma ait **oezgenc@gmail.com** elektronik posta adresine gönderilmesi, beni çok memnun edecektir.

19. basısı itibarıyla bu kitabın bütün telif hakları, Ceza Hukuku ve Adli Bilimler Vakfına devredilmiştir.

Başta Sayın Koray SEÇKİN olmak üzere, eserin basılmasında emeği geçen SEÇKİN Yayıncılık AŞ çalışanlarına teşekkür ederim.

Eserin Türk ceza hukuku düşüncesine katkıda bulunması dileklerle,

Ankara, 29 Temmuz 2024
İzzet ÖZGENÇ

Birinci Basıya İlişkin Önsöz

Ceza hukukunun genel hükümlerine ilişkin bir kanuni düzenlemenin içeriği, dayandığı teorik düşünce göz ardı edilerek anlaşılamaz.

Türkiye’deki eski kuşak ceza hukukçuları arasında 19. yüzyıl klasik suç teorisi hakimdir. Bu anlayışta, suçun yapısına ilişkin pek çok mesele nedensellik bağlantısı ile açıklanmaya çalışılıyordu. Bu anlayışta, *kast* ve *taksir*, birer “kusurluluk şekli” olarak görülmekteydi. Suçun *manevi unsuru* ile *kusurluluk* arasındaki ayırım, bu anlayışa yabancı idi. *Haksızlık* ile *hukuka aykırılık* kavramları arasındaki ayırım, klasik suç teorisine yabancı idi. *İşlenen fiilin bir haksızlık oluşturduğu hususundaki yanlış*, klasik suç teorisine mensup ceza hukukçularınca bilinen bir husus değildi. Bu nedenle, “Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” kuralıyla bağlantılı olarak, içinden çıkılmaz ve anlamsız birtakım tartışmaların içine girilmiştir. Klasik suç teorisinde, hukuka aykırılığın bir derecelendirmeye tabi tutulması mümkündü. Bu anlayışta, *hukuka uygunluk nedenleri* ile *kusurluluğu kaldıran nedenler* arasındaki nitelik farkı yeterince bilinmemekteydi ve genellikle sonuca bakılarak bir değerlendirme yapılmaktaydı. Buna rağmen, zorunluluk hali, bir “hukuka uygunluk nedeni”; “mücbir sebep” ise, kusurluluğu kaldıran bir neden olarak kabul edilmekteydi. *Kusurluluğu etkileyen nedenler* olarak, *kusurluluğu kaldıran* ve *azaltan nedenler* ayırımı, bu teoriye yabancı idi.

Bütün bu düşünceler dolayısıyla, bazı hukukçularımız tarafından, Ceza Muhakemesi Kanununda hüküm çeşidi olarak *beraat* kararı ile *ceza verilmesine yer olmadığı* kararı ayırımı yapmanın bir anlamı yoktur ve bu şekilde bir ayırım yapılması, Kanun koyucunun bir “çelişki”sinden ibarettir şeklinde değerlendirilmelerde bulunmaktadır.

Bu anlayışa göre, *ceza*, suç işleyen kişiye devlet eliyle uygulanan bir “kötülük”tü. Bu anlayış, kişiler gibi *devletin* de bir “hak sahibi”, “hak süjesi” olduğunu kabul etmekteydi ve cezalandırmak, devlet için bir “hak”tı.

Bu anlayış, *mağdur* ile *suçtan zarar gören* kavramları arasında ayırım gözetmemekteydi. Bu anlayışa göre, işlenen her suçun “mağdur”u aynı zamanda “devlet”ti.

Bu anlayışta, ceza hukuku yaptırımları arasında, sonradan kabul gören güvenlik tedbirlerinin yanı sıra, “fer’i ceza”ların da yer alması gerekmekteydi. Ancak, “fer’i ceza” ile güvenlik tedbiri arasında ne tür bir “nitelik farkı”nın bulunduğu hiç gündeme getirilmemekteydi.

Bu anlayışta müsadere, mahkumiyet şartına bağlı bir “ceza” idi. Bu anlayışta, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen kazancın müsadresi söz konusu değildi. Suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde

edilen kazancın devlete intikalini sağlamak için müsadereyi yanında ayrı bir yaptırım olarak “mülkiyetin devlete geçirilmesi” yaptırımının kabulü yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştı. Ancak, müsadere ile “mülkiyetin devlete geçirilmesi” yaptırımları arasında ne tür bir “nitelik farkı”nın bulunduğu izah edilmemekteydi.

Elinizdeki kitapta, ceza hukukunun genel hükümlerine ilişkin olarak yeni TCK’da yapılan düzenlemelerin arkasındaki teorik düşünceler, etraflı bir şekilde açıklanmaktadır.

Kitapta izlenen inceleme yöntemiyle, yeni TCK’nın benimsediği farklı felsefe ve sistem karşısında mevcut Yargıtay içtihatlarının işlevsiz kaldığı yönündeki endişelerin yersiz olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Bu eserle, Türk ceza hukuku düşüncesine katkıda bulunursam, bahtiyar olacağım.

Ankara, 6 Eylül 2006

İzzet ÖZGENÇ

İçindekiler

Yirminci Basıya İlişkin Önsöz	7
Birinci Basıya İlişkin Önsöz	9
Kısaltmalar	23

Birinci Bölüm CEZA HUKUKUNA GİRİŞ

§1. Suç ve Ceza Kavramları	25
Ekskurs 1. Fuhuş ve Hukuk	40
§2. Ceza Hukukunun Fonksiyonu	53
§3. Bir Bilim Dalı Olarak Ceza Hukuku	55
§4. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla Olan İlişkisi	58
§5. Türk Ceza Hukukunun Kaynakları	62
I. Doğrudan Kaynaklar	62
A. Anayasa	62
B. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar	65
C. Milletlerarası Sözleşmeler	69
II. Dolayısıyla Kaynaklar	77
A. Yüksek Mahkeme Kararları	77
B. Doktrin	79
§6. Türkiye’de Yeni Bir Ceza Kanunu Hazırlanmasını Gerektiren Nedenler ve Hazırlık Süreci	80
§7. Yeni TCK’nın Hazırlanmasında Etkili Olan Felsefi Düşünceler ve Kanunun Özellikleri	85
§8. Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi	108
§9. Suçların Tasnifi Sorunu – Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması	113
§10. Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu	120
I. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi	120
II. Suçta Kanunilik İlkesi ve “Beyaz Hüküm” Sorunu	123
III. Belirlilik İlkesi	131
IV. Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı	134
A. Yorum	134
B. Kıyas Yasağı	136
V. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi	140
VI. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması	140

A. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Zaman Bakımından Uygulama İlkeleri	140
B. Lehe Kanunun Belirlenmesinde İzlenmesi Gereken Yöntem	145
C. Ceza İnfaz Rejiminde Değişiklik Yapan Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması	149
D. Geçici ve Süreli Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu	153
E. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu	154
F. Lehe Olan Kanunun Geçmiş Etki Alanı ve Uygulanması	156
G. Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararlarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu...	157
H. Kabahatlerle İlgili Zaman Bakımından Uygulama Kuralları	159
§11. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı.....	160
I. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Yer Bakımından Uygulanması	160
II. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulanması	160

İkinci Bölüm SUÇ TEORİSİ

§12. Suçun Yapısını Açıklayan Teoriler.....	161
I. Klasik Suç Teorisi.....	161
II. Teleolojik (Neo Klasik) Suç Teorisi	165
III. Amaççı (Gaî, Final) Suç Teorisi	170
IV. Sentezci Yaklaşım	173
§13. Hukuki Değer İhlâli ve Haksızlık Teşkil Eden Bir Fiil Olarak Suç	176
§14. Suçun Maddi Unsurları	182
I. Bir Haksızlık Olarak Fiil.....	182
A. Tek veya Çok Hareketli Suçlar	186
B. Serbest Hareketli Suçlar	187
C. Bağlı Hareketli Suçlar	188
D. Seçimlik Hareketli Suçlar	188
E. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar	192
II. Netice.....	193
III. Nedensellik (İllyet) Bağlantısı.....	194
IV. Fail	214
A. "Özgü (Mahsus) Suç" Kavramı	214
B. Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olabilmesi Sorunu.....	216
C. Suç Nedeniyle Tüzel Kişinin Sorumluluğu	217
D. Kabahatlerden Dolayı Tüzel Kişinin Sorumluluğu.....	220
V. Suçun Konusu	222
A. Zarar Suçu - Tehlike Suçu Ayırımı	223
B. Soyut Tehlike Suçu - Somut Tehlike Suçu Ayırımı.....	224
VI. Mağdur	226
A. Genel Olarak Mağdur Kavramı	226

<i>B. Mağdur - Suçtan Zarar Gören Ayırımı</i>	227
VII. Suçun Nitelikli Unsurları	230
§15. Suçun Manevi Unsuru	234
I. Kast	235
A. <i>Bir Haksızlık Şekli Olarak Kast ve Kusurlulukla İlişkisi</i>	235
1) Doğrudan Kast	246
2) Olası (Muhtemel) Kast	247
B. <i>Doğrudan Kast ve Olası (Muhtemel) Kast Ayırımının Yasama Faaliyeti ve Uygulama Açısından Önemi</i>	254
II. Taksir	259
A. <i>Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir</i>	259
B. <i>Taksirli Haksızlık ve Netice İlişkisi</i>	272
C. <i>Taksirle İşlenen Fiilden Dolayı Kusurluluk</i>	278
D. <i>Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk</i>	279
E. <i>Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Kişisel ve Ailevi Durumu İtibarıyla Mağdur Olması</i>	286
F. <i>"Bilinçli Taksir" Kavramı</i>	290
III. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç	298
IV. Amaç veya Saik	303
V. Kabahatlerde Manevi Unsur	304
§16. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru	306
I. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı	306
II. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınıflandırılması Sorunu	316
III. Yeni Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri	318
A. <i>Hakkın Kullanılması</i>	318
B. <i>Görevin Yerine Getirilmesi</i>	325
Ekskurs 1. Kolluk Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi	326
Ekskurs 2. Görevin Yerine Getirilmesi Hukuka Uygunluk Sebebi Bağlamında Müdafilik Görevinin Kapsam ve Sınırları	345
Ekskurs 3. Kolluğun Suçlulukla Mücadele ve Suç Olaylarının Açıklığa Kavuşturulması Bağlamında Suç Oluşturan Fiilleri İşleyip İşleyemeyeceği Sorunu	350
Ekskurs 4. Kolluğun Sürücülerle İlgili Olarak Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Denetimi Yapma Yetkisi ve Sınırları	355
C. <i>Meşru Savunma</i>	361
D. <i>İlgilinin Rızası</i>	369
Ekskurs 5. Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler	384
Ekskurs 6. Sünnet Uygulamasının Hukuki Açidan Değerlendirilmesi	395
IV. Kabahatlerde Hukuka Aykırılık Unsuru ve Kabahatlerle İlgili Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması	397
§17. İhmalî Suçlar	398
§18. Kusurluluk	459

I. Normatif Bir Değer Yargısı Olarak Kusurluluk.....	459
II. Kasten İşlenen Suçlarda Kusurluluk.....	462
A. Algılama Yeteneği.....	463
1) Haksızlık Bilinci.....	463
2) Teorik Gelişim.....	464
B. İrade Yeteneği.....	466
1) Muaheze Yargısı ve İrade.....	466
2) İrade Hürriyeti.....	467
3) İrade Yeteneğinin Derecelendirilmeye Tabi Tutulması.....	469
III. Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluk.....	470
A. Algılama Yeteneği.....	470
B. İrade Yeteneği.....	471
IV. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler.....	471
A. Yaş Küçüklüğü.....	472
1) Birinci Grup Yaş Küçükleri.....	473
2) İkinci Grup Yaş Küçükleri.....	474
3) Üçüncü Grup Yaş Küçükleri.....	478
B. Akıl Hastalığı.....	480
C. Sağır ve Dilsizlik.....	485
D. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma.....	486
1) “Sebebinde Serbest Hareket” (actiones liberae in causa) Kavramı.....	486
2) İstemeyerek Sarhoşluk.....	488
3) İsteyerek Sarhoşluk.....	489
4) Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Kusur Yeteneği Sorunu.....	491
5) “Geçici Neden” Kavramı ve Lohusalık Dönemindeki Annenin Yeni Doğan Çocuğunu Yaralaması Veya Öldürmesi Dolayısıyla Ceza Hukuku Sorumluluğu.....	491
Ekskurs 7. Zorunluluk Haline İlişkin Kur’an Hükümlerinin Günümüz Hukuk Anlayışına Aktarılması Sorunu.....	494
E. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi.....	496
F. Zorunluluk Hali Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi.....	498
G. Hukuka Aykırı ve Fakat, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi.....	506
H. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması.....	513
İ. Haksız Tahrik.....	528
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri.....	539
V. Kabahat Dolayısıyla Kusurluluk.....	539
§19. Hata.....	540
I. Kastı Kaldıran Hata Halleri.....	540
A. Suçun Maddi Unsurlarında Hata.....	540
B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata.....	543
C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata.....	544
II. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri.....	551
A. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata.....	551
B. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata.....	553
III. Hata Hükümlerinin Kabahatler Hakkında Uygulanması.....	562

§20. Suça Teşebbüs.....	563
I. Teşebbüsün Hukuki Niteliği	563
II. Kasten İşlenen Suçun Varlığı.....	565
III. Hazırlık ve İcra Hareketleri.....	568
IV. Elverişlilik Sorunu	578
V. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcrasının Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi.....	582
VI. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu.....	587
VII. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara Teşebbüs Sorunu	587
VIII. İhmalî Suçlara Teşebbüs Sorunu	588
IX. Gönüllü Vazgeçme	590
X. Kabahate Teşebbüs	599
§21. Suça İştirak.....	600
I. Faillik.....	600
A. Çok Failli Suçlar	600
B. Suça İştirakin Hukuki Esası	602
C. Müşterek Faillik.....	606
1) Suçun İşlenişi Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurulması	606
2) Birlikte Suç İşleme Kararı	619
3) Özgü Suçlarda Müşterek Faillik.....	629
4) İhmalî Suçlarda Müşterek Faillik	631
5) Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik	631
D. Dolaylı Faillik.....	632
II. Şeriklik	635
A. Azmettirme	635
B. Yardım Etme.....	641
III. Bağlılık Kuralı	649
Ekskurs 8. Bağlılık Kuralına İlişkin Uygulama Sorunu	657
IV. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme	670
V. Kabahate İştirak.....	673
§22. Suçların İçtimaı.....	675
I. Kural: Gerçek İçtima	675
II. Bileşik Suç	679
III. Zincirleme Suç.....	684
IV. Aynı Neviden Fikrî İçtima.....	702
Ekskurs 9: Yağma Suçu İle İlgili İçtima Sorunu ve Yargıtay Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler	714
V. Farklı Neviden Fikrî İçtima	718
VI. Suç ve Kabahatin İçtimaı	746

§23. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları	753
I. Şahsi Cezasızlık Sebepleri	753
II. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler	768
III. Ortak Özellikleri	772
IV. Objektif Cezalandırılabilme Şartları	774
§24. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları	779
I. Genel Olarak	779
II. Şikâyet	780
III. İzin, Talep ve Karar	786

Üçüncü Bölüm YAPTIRIM TEORİSİ

§25. Ceza Hukuku Yaptırımlarının Türleri, Amaçları ve Nitelikleri	791
I. Yaptırım Türü Olarak Ceza ve Güvenlik Tedbiri	791
II. Kusur ve Ceza İlişkisi: nulla poena sine culpa	792
III. Ceza Yaptırımının İnsan Haysiyetiyle Bağdaşır Nitelikte Olması Prensibi	799
Ekskurs 1. Kur'an'daki Ceza İle İlgili Hükümlerin Günümüz Hukuk Anlayışına Aktarılması	801
IV. Ölüm Cezası	806
V. Hapis Cezası	810
VI. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar	812
A. <i>Cezaya Mahkumiyete Engel Olan Seçenek Kurumlar</i>	814
1) Uzlaşma	814
2) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi	815
3) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması	815
4) Adli Para Cezasına Hükmetme	827
5) Önödeme	827
a) Tanımı ve Hukuki Niteliği	827
b) Önödemenin Koşulları	829
B. <i>Hapis Cezasının İnfazı Bakımından Seçenek Kurumlar: Hapis Cezasının Toplumsal Ortamda İnfazı</i>	838
1) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma	839
2) Belli Bir Eğitim Programına Katılma	840
3) Zararın Tazmini	840
VII. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi	844
VIII. Hapis Cezasının Ertelenmesi	855
A. <i>Ertelemenin Amacı ve Hukuki Niteliği</i>	855
B. <i>Koşulları</i>	857
1) Hükmolunan Cezanın Türü ve Miktarına İlişkin Koşul	857
2) Failin Geçmişine İlişkin Koşul	861

3) Ertelemeye Liyakat Koşulu	865
<i>C. Erteleme Kararı</i>	<i>865</i>
<i>D. Erteleme Kararının Sonuçları, Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri</i>	<i>870</i>
1) Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi, Bu Süre Zarfında Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklerle Uygun Davranılmış Olması	871
2) Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklerle Uygun Davranılmamış Olması	872
IX. Koşullu Salıverilme	874
<i>A. Amacı ve Hukuki Niteliği</i>	<i>874</i>
<i>B. Koşulları</i>	<i>875</i>
1) Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Koşullar	875
2) Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Koşullar	888
<i>C. Hükümlünün Koşullu Salıverilmeye Hazırlanması</i>	<i>889</i>
<i>D. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi</i>	<i>890</i>
<i>E. Cezanın Kalan Kısmının Kurum Dışında İnfaz Edilmesi</i>	<i>891</i>
<i>F. Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi</i>	<i>893</i>
<i>G. Denetim Süresi İçinde Yükümlülüklerle Aykırı Hareket Edilmesi veya Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi</i>	<i>893</i>
X. Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı	899
XI. Özel İnfaz Şekilleri	904
<i>A. Hafta Sonu veya Geceleri İnfaz</i>	<i>904</i>
<i>B. Konutta İnfaz</i>	<i>905</i>
<i>C. Ortak Hükümler</i>	<i>906</i>
XII. Hapis Cezası ve Disiplin Hapsi	907
XIII. Adli Para Cezası	911
XIV. Cezaların İnfazı	920
<i>A. Genel Olarak</i>	<i>920</i>
<i>B. Hapis Cezasının İnfazı</i>	<i>922</i>
<i>C. Hükümlülerin Tasnifi</i>	<i>924</i>
<i>Ç. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler</i>	<i>926</i>
<i>D. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler</i>	<i>927</i>
<i>E. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler</i>	<i>930</i>
<i>F. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı</i>	<i>932</i>
<i>G. Müebbet Hapis ve Süreli Hapis Cezasının İnfazı</i>	<i>933</i>
<i>H. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi</i>	<i>933</i>
1) Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi	934
2) Çocuğunun Hastalığı Nedeniyle Kadın Hükümlünün Cezasının İnfazının Ertelenmesi	935
3) Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün Talebiyle Ertelenmesi	936
4) Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması	938
<i>I. Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi ve Haberleşmesi</i>	<i>940</i>
1) Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi	940
2) Hükümlülerin Dışarıyla Haberleşmesi	948

<i>J. Hükümlülerin Çalıştırılması</i>	953
<i>K. Hükümlünün İnfaz Kurumunda Hastalanması</i>	955
<i>L. Hükümlülerin İzinli Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılması</i>	957
<i>M. Adli Para Cezasının İnfazı</i>	960
Ekskurs 2. İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi	964
XV. Güvenlik Tedbiri	968
XVI. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma	974
XVII. Eşya Müsaderesi	999
XVIII. Kazanç Müsaderesi.....	1003
Ekskurs 3. Şirket Malvarlığının Müsaderesi	1017
Ekskurs 4. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi	1018
XIX. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri	1020
XX. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri	1021
XXI. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri	1023
A. Tekerrürün Hukuki Niteliği	1023
B. Tekerrürün Koşulları	1024
C. Tekerrürün Sonuçları	1028
D. Diğer Tehlikeli Suçlulara İlişkin İnfaz Rejimi	1033
E. Terör Suçları Dolayısıyla Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Özel Tekerrür.....	1034
Ekskurs 5. Kabahatlerde Tekerrür Sorunu.....	1036
XXII. Sınır Dışı Edilme	1038
XXIII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri	1039
XXIV. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Güvenlik Tedbirleri	1043
XXV. Denetimli Serbestlik Tedbiri	1047
§26. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi.....	1051
I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi	1051
II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi	1061
A. Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi	1061
B. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi	1064
III. Suçun Nitelikli Halleri.....	1065
IV. Suçun Özel Görünüş Biçimleri	1068
V. Kusurluluğu Azaltan Nedenler	1069
VI. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler	1071
VII. Takdiri İndirim Nedenleri	1072
VIII. Sonuç Ceza Bakımından Sınırlama.....	1075
IX. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesiyle İlgili Örnekler	1075
Ekskurs 6. Seri Muhakeme Usulünde Hükmolunacak Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Bağlamında Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerisi	1080
X. Mahsup	1081

§27. Davanın veya Cezanın Düşmesi.....	1088
I. Dava Zamanaşımı.....	1088
II. Dava Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi.....	1094
III. Dava Zamanaşımı ve Muhakeme Şartı Olarak Dava Süresi	1100
IV. Ceza Zamanaşımı.....	1101
V. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi veya Durması	1102
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımına İlişkin Ortak Hükümler	1104
VII. Kabahatlerde Zamanaşımı.....	1104
VIII. Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Fiiller Dolayısıyla Zamanaşımı	1106
IX. Şikâyetten Vazgeçme.....	1106
X. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü	1108
XI. Af	1109
XII. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi.....	1111

Dördüncü Bölüm

MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU

§28. Ceza Hukukuna İlişkin Türk Kanunlarının Uygulama Alanı	1113
I. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından Kural.....	1113
II. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Bakımından İlkeler	1122
A. <i>Faile Göre Şahsilik İlkesi</i>	1122
1) Görev Suçlarına İlişkin İlke	1122
2) Vatandaş Tarafından İşlenen Suç	1123
B. <i>Mağdura Göre Şahsilik İlkesi</i>	1130
C. <i>Evrensellik ve Koruma İlkesi</i>	1134
D. <i>Yurt Dışında Verilmiş Olan Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları</i>	1151
III. Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanına İlişkin Kuralların Kabahatler Bakımından Uygulanması	1153
§29. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması	1154
§30. İade.....	1156
I. Giriş.....	1156
II. İade Kavramı, İade Kurumunun Hukuki Dayanağı ve Niteliği, Tarihi Gelişimi.....	1156
A. <i>Genel Olarak</i>	1156
B. <i>Sığınma ve İade İlişkisi</i>	1158
C. <i>İadenin Sınır Dışı Etmeden Farkları</i>	1160
D. <i>İade ve “Takas” İlişkisi</i>	1163
E. <i>İade Kurumunun Tarihi Gelişimi</i>	1168
III. İade Hukukunun Kaynakları ve Birbirleriyle İlişkisi	1169
A. <i>İade Hukukunun Kaynakları</i>	1169

<i>B. Kaynaklar Arasındaki İlişki</i>	<i>1182</i>
IV. İadenin Koşulları	1184
V. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Karşılığı Olarak Öngörülen Yaptırımın Niteliği Dolayısıyla Geriverme Sorunu.....	1188
<i>A. Yaptırım Olarak Güvenlik Tedbiri Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu.....</i>	<i>1188</i>
<i>B. Adli Para Cezası Gibi Mali Nitelikte Yaptırımı Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu</i>	<i>1189</i>
<i>C. Ölüm Cezası ve İade Sorunu</i>	<i>1189</i>
VI. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Niteliği Dolayısıyla İade Sorunu	1191
<i>A. Siyasi Suçlar Nedeniyle İade Sorunu.....</i>	<i>1191</i>
<i>B. Terör Eylemleri Nedeniyle İade Sorunu</i>	<i>1195</i>
<i>C. Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu</i>	<i>1199</i>
<i>D. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suçun Siyasi Suç Olup Olmadığını Takdir Yetkisi.....</i>	<i>1199</i>
<i>E. Siyasi Suç Nedeniyle İade Etmemenin Sonuçları.....</i>	<i>1200</i>
<i>F. Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu</i>	<i>1201</i>
<i>G. Basın Suçları Nedeniyle İade Sorunu.....</i>	<i>1202</i>
<i>H. Askeri Suçlar Nedeniyle İade Sorunu.....</i>	<i>1203</i>
<i>İ. Mali Suçlar Nedeniyle İade Sorunu.....</i>	<i>1203</i>
<i>J. Uyuşturucu Madde Suçları ve İade.....</i>	<i>1204</i>
VII. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Dolayısıyla Talepte Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisine Sahip Olması	1206
<i>A. Suçun, Talepte Bulunulan Devletin Ülkesinde İşlenmiş Olması</i>	<i>1206</i>
<i>B. Suçun Kendi Ülkesi Dışında İşlenmesine Rağmen, İade Talebinde Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisinin Olması</i>	<i>1206</i>
VIII. “Non Bis In Idem” Kuralı ve İade Sorunu. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Nedeniyle Kişi Hakkında Talepte Bulunulan Devlet Yargı Organlarınca Karar Verilmiş Olması	1208
IX. Vatandaşın İade Edilmemesi Kuralı	1209
X. Özel Haller Sebebiyle İade Sorunu.....	1211
XI. İade Usulü	1211
<i>A. İade Talebinde Bulunulması ve Talepname (Talep Belgesi)</i>	<i>1211</i>
<i>B. Talepnamenin İncelenmesi.....</i>	<i>1213</i>
<i>C. İade Sürecinde Koruma Tedbirleri</i>	<i>1215</i>
1) Geçici Tutuklama	1215
2) Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri	1217
<i>D. Birden Fazla İade Talebi Karşısında Karar Verilmesi</i>	<i>1218</i>
<i>E. İade Talebinde Bulunulmasının Teklif Edilmesi.....</i>	<i>1218</i>
<i>F. İadesine Karar Verilen Kişinin Talepte Bulunan Devlete Teslim Edilmesi.....</i>	<i>1219</i>
<i>G. Teslimin Ertelenmesi</i>	<i>1220</i>
<i>H. Geçici İade.....</i>	<i>1221</i>
<i>İ. Eşya ve Değerlerin Teslimi.....</i>	<i>1221</i>
<i>J. İade Harcamaları ve Bu Harcamaların Karşıllanması.....</i>	<i>1221</i>
XII. İadenin Sonuçları	1222
<i>A. İadede Özellik Kuralı.....</i>	<i>1222</i>

<i>B. İadeye Neden Olan Fiilin Niteliğinde Değişiklik Meydana Gelmesi</i>	<i>1223</i>
<i>C. Özellik Kuralının Etkisinin Ortadan Kalktığı Haller.....</i>	<i>1223</i>
1) İade Eden Devletin Talepnamede Belirtilmeyen Suçlar Dolayısıyla da Yargılamaya İzin Vermesi	1223
2) İade Edilen Kişinin Rıza Göstermesi	1224
3) Belirli Bir Sürenin Geçmesine Rağmen Ülkenin Terk Edilmemesi veya Tekrar Geri Gelinmesi.....	1224
4) Üçüncü Bir Devlete Yeniden İade.....	1224
<i>D. İade Edilen Kişinin Yargılanması ve Yargılama Sonucu Hakkında İade Eden Devlete Bilgi Verilmesi</i>	<i>1225</i>
XIII. Milletlerarası Ceza Hukuku Sorunu Olarak, İade Alanında “Male Captus, Bene Detentus” Prensibi	1225
Yararlanılan Kaynaklar	1229
Dizin	1255

Kısaltmalar

AIHS:	Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Any.:	Anayasa
Any. Mahkemesi:	Anayasa Mahkemesi
AÜSBFD:	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (müteakip veriler cilt, yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
BGH:	Bundesgerichtshof
BGHSt:	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (müteakip veriler cilt ve sahife numarasını göstermektedir.)
bkz.:	Bakınız
C.:	Cilt
CD:	Yargıtay Ceza Dairesi
CGK:	Yargıtay Ceza Genel Kurulu
CHD:	Ceza Hukuku Dergisi (müteakip veriler yıl, sayı, basım ayı ve sahife numarasını göstermektedir.)
CKAAS:	Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi
CK. veya C.Kanunu:	Ceza Kanunu
CMK:	Ceza Muhakemesi Kanunu
CYMDAS:	Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi
ÇKK:	Çocuk Koruma Kanunu
DEÜHFD:	Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (müteakip veriler cilt, yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
Deutsche StrafrZtg.:	Deutsche Strafrechtszeitung (müteakip veriler cilt, yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
DMK:	Devlet Memurları Kanunu
dn.:	Dipnot
DRiZ:	Deutsche Richterzeitung (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
F.:	Festschrift
f.:	Fıkra
GA:	Goldammer's Archiv für Strafrecht und Strafprozeßrecht (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
GS:	Zeitschrift "Der Gerichtssaal" (müteakip veriler cilt, yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
İHFM:	İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (müteakip veriler cilt, yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
İnfaz K.:	Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Jahrg.:	Jahrgang
JR:	Zeitschrift "Juristische Rundschau" (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
JuS:	Zeitschrift "Juristische Schulung" (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
JW:	Juristische Wochenschrift (Müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)

JZ:	Juristenzeitung (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
KHukA:	Kamu Hukuku Arşivi
KMK:	Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
kn.:	Kenar numarası
Lb.:	Lehrbuch
LK(8) veya LK(10):	Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch (8. veya 10. Bası)
LM:	Lindenmaier/Möhring: Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofes (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
m.:	Madde
MDR:	Zeitschrift "Monatsschrift für Deutsches Recht" (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
NJW:	Zeitschrift "Neue Juristische Wochenschrift" (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
NStZ:	Neue Zeitschrift für Strafrecht (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
OWiG:	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
§ veya §§:	Paragraf veya paragraflar
PVSK:	Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
RG.:	Resmi Gazete
RG.:	Reichsgericht
RGSt:	Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen (müteakip veriler cilt ve sahife numarasını göstermektedir.)
S.:	Seite
SchZStr.:	Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (müteakip veriler cilt, yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
sh.:	Sahife
SİDAS:	Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi
SJZ:	Süddeutsche Juristenzeitung (müteakip veriler yıl ve sütun numarasını göstermektedir.)
SK:	Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch
StGB:	Strafgesetzbuch
Stub.:	Studienbuch
SÜHFD:	Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (müteakip veriler cilt, yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
TCK:	Türk Ceza Kanunu
TMK:	Terörle Mücadele Kanunu
v.:	von
vd.:	ve devamı
Vorbem. vor:	Vorbemerkungen vor
YD:	Yargıtay Dergisi (müteakip veriler cilt, yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
YKD:	Yargıtay Kararları Dergisi (müteakip veriler yıl ve sahife numarasını göstermektedir.)
ZStW:	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (müteakip veriler cilt, yıl ve sahife numaralarını göstermektedir.)

Birinci Bölüm CEZA HUKUKUNA GİRİŞ

§1. Suç ve Ceza Kavramları

İnsanı diğer canlılardan ayıran tabîî özellik, onun *şahsiyet* sahibi oluşudur. Şahsiyet, insanın kendi varlığının şuurunda olmasını ve yine, idrak ve iradesiyle fiillerine hakim olmasını ifade etmektedir¹. Kendi varlığının şuurunda olan insan, çevresinde cereyan eden olayları hadiseleri, vakıaları, olguları gözlemleme, müşahade etme yeteneğine sahiptir. Bu yeteneği sayesinde insan, bu olguları maddi yönü itibarıyla müşahade edip, bunlardan belli sonuçlar çıkarabilmekte, belli yargılara varabilmektedir². İnsan, çıkardığı bu sonuçlar, vardığı bu yargılar ışığında -prensip olarak- davranışlarını serbestçe tayin etme hürriyetine sahiptir. İnsanın bu *davranışlarına hakim olabilme yeteneği*, doğal ve sosyal çevre şartları gibi haricî etkilerin yanı sıra, sevki tabîîler, dürtüler gibi dahilî etkilere maruzdur³. Bu nedenle, insanın irade (davranışlarına hakim olabilme) yeteneği, statik olmayıp; her somut olayda haricî ve dahilî faktörlerden etkileşim, az veya çok, önemli veya önemsiz derecede, mutlaka mevcuttur⁴. İnsan davranışında bazı illî faktörlerin etkili olması, insanın irade hürriyetini inkâr eden *determinist* anlayışa haklılık kazandırmaz. İnsan, yaratılmışlık vasfı dolayısıyla, evrene hakim olan varlık düzeni karşısında tam bir "otonom" (muhtar) olarak değil⁵; "heteronom" bir varlık olarak telâkki edilmelidir. Yani, insanın davranış hürriyeti, bu sözünü ettiğimiz varlıklar alemine hakim olan düzen karşısında *nispî bir hürriyettir*⁶. Bu nedenledir ki; insanın irade hürriyetinin kabulü, hayatının akışında kendisine yönelik hiçbir kuralın konulamayacağı şeklinde bir sonuca, yani, mutlak bir otonomluk anlayışına bizi götürmemelidir⁷.

¹ KAUFMANN, Arthur: *Das Schuldprinzip*, Heidelberg, 1961, sh. 116 vd.; aynı yazar: *Recht und Sittlichkeit*, Tübingen, 1964, sh. 11/12.

² DREHER, Eduard: *Die Willensfreiheit*, München, 1987, sh. 380.

³ İnsanın iç dünyasında, örneğin hayatta kalmaya, yemeye içmeye, cinsel arzuların tatminine, mal iktisap etmeye yönelik **dürtülerin, içgüdülerin** yanı sıra; gerçekleştirdiği ahlaken tasvip edilmez davranışların yanlış olduğu hususunda kişiye uyarıda bulunan **vicdan** olmak üzere, iki unsur mevcuttur (Kur'an-i Kerim, Kâf Süresi[50], Ayet, 21). Bu iki unsur, insan üzerinde egemenlik kurma yarışı vermektedir (Kur'an-i Kerim, Kâf Süresi[50], Ayet 17, 18).

⁴ Arth. KAUFMANN, *Schuldprinzip*, sh. 116 vd.; DREHER, sh. 395 vd. Ayrıca bkz. GÜRİZ, Adnan: *Hukuk Felsefesi*, Ankara, 1985, sh. 110 vd.

⁵ Kur'an-i Kerim, Necm Süresi(53), Ayet, 24; Kıyamet Süresi(75), Ayet 36.

⁶ Arth. KAUFMANN, *Schuldprinzip*, sh. 122/123.

⁷ "freie Entfaltung der Persönlichkeit": Arth. KAUFMANN, *Recht und Sittlichkeit*, sh. 21/22.

İnsanın varoluş amacı, *şahsiyetini serbestçe tekâmül ettirmektir*^{8,9}. Toplumun bir örgütleşmiş şekli olan *devletin amacı*, insana kendi şahsiyetini serbestçe tekâmül ettirme imkânlarını sağlamaktır¹⁰.

İnsanın şahsiyetini tekâmül ettirmesi, muhatabı olduğu *davranış normlarına* uygun bir şekilde hayatını yönlendirmesiyle mümkündür¹¹. Dolayısıyla, bu tekâmül, keyfi ve tesadüfi bir şekilde değil; her insan için ancak bilinçli bir şekilde icra edilecek bir *görevdir*, bir *yükümlülüktür*. İnsanın sahip olduğu bütün değerler, ancak bu tekâmül hedefine uygun bir şekilde kullanıldığı takdirde bir anlam ifade edecektir.

İnsanın kendi şahsiyetini tekâmül ettirmesi, kendi ihtiyarında olan bir husustur. Yani insan, tekâmül yoluna girip girmeme konusunda *irade serbestisine* sahiptir¹². İnsan, yaratılışı gereği, bu tekâmül sürecine girebilecek ve bu süreci başarıyla tamamlayabilecek maddi ve manevi donanıma sahiptir.

Sahip olduğu bu serbesti dolayısıyla; insan bu yükümlülüğüne uygun hareket etmeye zorlanamaz, bu doğrultuda zora, cebre, dayatmaya maruz bırakılamaz. Dolayısıyla; insanın tekâmül yolunu seçme doğrultusundaki yükümlülüğü, bir "*ahlâkî yükümlülük*"tür.

Davranış normları, insanın tekâmül sürecinde, hayatının akışı içinde davranışlarını yaratılış amacına uygun bir şekilde yönlendirebilmesi için vaz'edilmiş, konulmuş kaideler bütünüdür. Davranış normları, insan şahsiyetinin tekâmülünü sağlayacak ölçüt, nümune, örnek davranışları tayin etmektedir (*düstur-ul-amel*).

⁸ İnsanın yaratılış amacı, münhasıran Allah'a kulluk etmektir (Kur'an-i Kerîm, Zariyat Süresi[51], Ayet, 56). İnsan, imtihan edilmek, sınanmak amacıyla yaratılmıştır (Kur'an-i Kerîm, İnsan Süresi[76], Ayet 2). İnsan, amaçsız olarak, boş yere yaratılmamıştır (Kur'an-i Kerîm, Mü'minün Süresi[23], Ayet 115).

Diğer varlıklara nazaran üstün kılınan insanlar arasındaki *erdemlilik* ve *fazilet* yönünden tek üstünlük (**eqrem**) ölçütü **takva**dır. Yani, yükümlülüklerinin ve bunlara aykırı davranması halinde mutlaka sorumlu olacağının bilincinde olarak davranan, bu bilinçle hayatını yönlendiren insan; değer itibarıyla üstünlüğü haiz insandır (Kur'an-i Kerîm, Hücurat Süresi[49], Ayet 13).

Takva, insanın, yükümlülüklerinin ve bunlara aykırı davranışta bulunması halinde mutlaka sorumlu olacağının *bilincinde* olmasını ifade etmektedir. Başka bir deyişle, takva; Rabbinin kendisine "şah damarından daha yakın" (Kur'an-i Kerîm, Kâf Süresi [50], Ayet 16) olduğu bilinciyle, Rabbine hiçbir iyilik veya kötülüğün gizli kalmayacağı (Kur'an-i Kerîm, Lokman Süresi[31], Ayet 16) bilinciyle; kişinin davranışlarını yönlendirmesi ve bu davranışlarından dolayı mutlaka sorumlu tutulacağının idrakinde olmasıdır. Bu itibarla, "**takva sahibi**" (muttaki) kavramı ile, bütün davranışlarından dolayı Allah'a karşı **sorumluluk bilincinde** olan kişiye işaret edilmektedir.

⁹ Max SCHELER'den naklen Arth. KAUFMANN, Recht und Sittlichkeit, sh. 12.

¹⁰ Bkz. 1982 Anayasası, "Başlangıç" bölümü, ayrıca m. 5 ("insanın maddi ve manevî varlığının gelişmesi"); keza, 1948 Alman Anayasası, m. 2, f. 1.

¹¹ Arth. KAUFMANN, Recht und Sittlichkeit, sh. 21/22.

¹² İmtihan amacıyla yaratılmış olan insana, bu sınanma sürecinde doğru yol da gösterilmiştir. Ancak kişi doğru yolu tercih edip etmemek hususunda serbest (özgür) bırakılmıştır (Kur'an-i Kerîm, İnsan Süresi[76], Ayet 3).

Bu normların esasını, olması gereken insan davranışları, belli bir gayeye matuf (gaî, final, ereksel) fiiller oluşturmaktadır^{13,14}.

Davranış normları, devletin müdahalesinden bağımsız bir mevcudiyete, devletin varlığına öngelen bir yapıya sahiptirler¹⁵. Bu normlar, *özel bir bilgi* tarzı ile kavranabilirler. Bu özel bilgi, *hikmet bilgisidir, filozofidir, felsefedir*. Bu bilgi ile *ilmî bilgi* arasında birtakım farklılıklar mevcuttur^{16,17}.

¹³ KAUFMANN, Armin: *Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, Normlogik und moderne Strafrechtsdogmatik*, Göttingen, 1954 (erweiterter Nachdruck der 1. Auflage: Göttingen, 1988), sh. 71 vd., 102, 107, 125, 282, 284. Erem, bu normları “hukuk düzeninin yüksek prensipleri” olarak ifade etmektedir (EREM, Faruk: *Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, cilt I, 12. bası, Ankara 1984, sh. 39).

¹⁴ İnsanın erdemlilik sürecinde mesafe katetmesi, ancak “**salih fiiller**”le mümkündür (Kur’an-i Kerim, Teğabün Süresi[64], Ayet 9; Talak Süresi[65], Ayet 11; Asr Süresi[100], Ayet 3). “*Salih fiiller*”, davranış normlarının gereklerini ifade etmektedir.

¹⁵ ÇOBANOĞLU, Rahmi: *Hukukta Gaye Problemi*, İstanbul, 1964, sh. 29. Ozansü, insanın “kendisiyle ilgili olan kuralların bilincine varmakla” kişilik kazandığını ifade etmektedir (OZANSÜ, Mehmet Cemil: *Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk*, Ankara 2007, sh. 20, 21). Ancak, yazar aynı zamanda insanın “*kendi(sinin) de bir kural koyucu olduğundan*” söz etmektedir (OZANSÜ, Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 21). İnsan, “*bir olması gereken yaratıcısıdır ve ... objektif olması gerekeni, yani normu belirleyen hukuku kendisi yarat*”maktadır (OZANSÜ, Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 54). Yazarın bu açıklamaları, bir çelişki içermektedir. İnsan, ancak kendisi dışında konulan davranış normlarının içeriğine yönelik idrakte kendi varlığının bilincine ulaşmaktadır. Bu itibarla, kişinin kendi varlığının bilincine varabilmesi için bu normların içeriğine yönelik bilgiye sahip olması gerekmektedir. Kişi kendi varlığının bilincine varduktan sonra kural koyabilecektir. Ancak bu kurallar, pozitif hukuk kuralları olup, bunların ana çıkış noktasını ve meşruluk zeminini davranış normları oluşturur. Yazar, bu noktada, *Kant*’ın düşünce yapısına nazaran önemli farklılık içeren *Hegel*’in düşüncelerinden esinlenmiş gözükmektedir.

¹⁶ Bu farklılıkları şu şekilde özetleyebiliriz:

İlim, idrak aleminin haricen kavranmasına ilişkin bilgiyi ifade etmektedir. Yani, ilim, gerçeği olduğu gibi kabul eder ve onun halihazırdaki görünüş biçimiyle yetinir. Buna karşılık; hikmet (=filozofi, felsefe) ise, hadiselerin, fiil ve hareketlerin, realitenin derunen, manen kavranmasını, anlaşılmasını sağlayan bilgidir (ÇAĞIL, Orhan Münir: *Hukuk Metodolojisi Dersleri*, 3. bası, İstanbul, 1962, sh. 2 vd.). İlimin görevi, belli bir metod dahilinde hadiseler hakkında bilgi edinmektir. Buna karşılık; hikmetin görevi ise, eşyanın hakikatını, hakîki mahiyetini ve derunî insicamını kavramak ve izah etmektir. Bir başka ifadeyle; evreni bir bütün olarak kavrama uğruna sarfedilen bir gayrettir (ÇAĞIL, sh. 7, 15).

İlim ve hikmet (felsefe), birbirini tamamlayan iki bilgi tarzıdır. Bu iki bilgi tarzından hiçbirini diğerinden vazgeçemez. (ÇAĞIL, sh. 3, 16/17). Felsefesiz ilim, kuru bir bilgidir; ilimsiz felsefe de, çelişkiler ve yanlışlarla iştigalden başka bir şey değildir.

İlim ve hikmet bilgisine insanların vukufiyeti *nisbîdir*. Bu nisbîlik, içinde yaşanılan sosyal çevre, kültür ortamı ve hatta şahıs itibarıylaadır.

Bu bağlamda “*Lumbee Kabilesi*”ne izafe edilen bir sözü iktibas etmekte fayda mülâhaza etmekteyiz:

“*Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazi, hikmet ise istikbaldir.*”

Hikmete vakıf olmadan bilgi sahibi olan kişi ile ilgili olarak, “*kitap yüklü eşek*” benzetmesi yapılmıştır (Kur’an-i Kerim, Cuma Süresi[62], Ayet 5).

¹⁷ Nitekim Erem de, “felsefe bilgisi”ni kastederek, “ilim bilgisinden başka bir bilgi(nin) daha var”lığı fikrindedir (EREM, Genel Hükümler I, 12. bası, sh. 16).

Bir devlete *Hukuk Devleti* vasfını kazandıran husus, bu davranış normlarını esas alan mevzuatı (anayasa, kanun vs.) hayata geçirmesidir¹⁸. Bu anlamda davranış normları, pozitif (mevzu') hukuk için bir "örnek" teşkil etmektedir; bir başka ifadeyle, "pozitif hukukun bir esin (ilham) kaynağı rolünü oynama"ktadır¹⁹. Hukuk toplumuna hayatiyet kazandıran *değerlerin* dayanağını, bu normlar oluşturmaktadır.

Davranış normlarının en önemli özelliği, *fitrî* oluşlarıdır²⁰. Yani, bu normların icapları (gerekleri) hiçbir zaman insanın doğasıyla, tabiatıyla çelişki arz etmez²¹. Bu itibarla, hangi kültür ortamında yaşanırsa yaşansın, hangi dünya görüşü benimsenirse benimsensin, söz konusu davranış normlarının muhtevasının -hiç olmazsa ana hatlarıyla- belirlenmesinde bütün insanlık fikir birliği içindedir^{22, 23}.

¹⁸ Aynı mealde MUMCU, Ahmet: *İnsan Hakları, Kamu Özgürlükleri*, Ankara, 1992, sh. 7; ÇAĞIL, sh. 99 vd.; BENDA, Ernst: *Die Menschenwürde*, in: Benda/Maihofer/Vogel, Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin-New York, 1983, sh. 108.

¹⁹ ARAL, Vecdi: *Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine*, 6. bası, İstanbul, 1991, sh. 46.

²⁰ Meselâ bkz. BOCKELMANN, Paul: *Vom Sinn der Strafe*, in: Heidelberger Jahrbücher, Band V, Heidelberg, 1961, sh. 26; *Binding*'in aynı mealde görüşü için bkz. Arm. KAUFMANN, Normentheorie, sh. 7.

²¹ Arth. KAUFMANN, Schuldprinzip, sh. 122, 127.

²² ÇAĞIL, bu normların "ideel bir merciden" kaynaklandıklarını söylemektedir (sh. 108, 110). Keza, Ateş'in şu ifadeleri, mes'elenin kavranması açısından yol göstericidir: "Reşit bir insan olarak fert, *insanlarüstü düzenlenmiş bir kuvvetin* yönetiminde mevcuttur. Özgürlüğü, belirli bir değerler sistemi içerisindeki seçimden ibarettir" (ATEŞ, Toktamış: *Demokrasi -Kavram, Tarihi Süreç, İlkeler-*, 3. bası, Ankara, 1994, sh. 26.). Buna karşılık, Erem, "*insanlık kuralları*" olarak tavsif ettiği bu ölçünün kaynağının, "*insanlığın müşterek vicdanı*" olduğu kanaatinde (EREM, Genel Hükümler I, 12. bası, sh. 13, 39).

²³ Pozitif (mevzu') hukuka öngelen ve bütün insanlar için geçerli telâkki edilen prensiplerden oluşan bir hukuk nizamının mevcudiyeti (*tabii hukuk*), felsefe tarihinde sürekli savunulagelen bir husustur. Bu hukuk nizamının "*insanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan bir hukuk*" olduğundan söz edilmektedir (MUMCU, sh. 5). Bu hukuk nizamının ilkeleri, "*insanın doğasına, evrensel ahlâk kurallarına ve akıl ile vicdanına uygun*"luk arzetmektedirler (MUMCU, sh. 6).

Genellikle (!) doğru teşhis edilmiş olan bu "*evrensel hukuk ilkeleri*"nin, bu "*evrensel ahlâk kuralları*"nın tek kaynağı *İlâhî Risalettir*. Bir başka ifadeyle, bu genel ilkeler, İlâhî Mesajda yer alan davranış normlarından çıkarılarak formüle edilmişlerdir.

Sekülerist dünya görüşüne mensup düşünürler, bu evrensel değerlerin ve onların dayanağını teşkil eden normların kaynağının "akıl" olduğunu iddia etmektedirler. Bilinmesi gerekir ki; aklın nesnesi yoktur; akletmek şahsiyet sahibi insanın idrak kabiliyetiyle alâkalı bir fonksiyondur. Dolayısıyla, **akıl, bir bilginin kaynağı olamaz**. Akletmek, insanın kendi varlığının şuurunda olarak çevresindeki vakıaları, olguları müşahade edebilme ve bu müşahadesinden belli sonuçlar çıkarabilme, belli yargılara varabilme *kabiliyetidir*. Bir başka ifadeyle; akletme, belli verilerden insanın belli sonuçlar çıkarabilme yeteneğidir. Bu fonksiyonun insan tarafından doğru veya yanlış bir şekilde icra edilmesi mümkündür. Bu izahatımız karşısında; insan, yaşadığı tabii ve sosyal çevredeki ilişkileri müşahade ederek; aslında kendi fitratına uygun olan, kendi yaratılışına hakim tabii özelliklere uygun olan bazı kuralları, prensipleri doğru bir şekilde tesbit edebilir. Fakat, bu vakia, tesbit edilen kuralların, prensiplerin kaynağının akıl

Davranış normlarının muhatabı, *insandır*²⁴. Kusur ehliyetine sahip olup olmadığına bakılmaksızın, *herkes* bu normların muhatabıdır²⁵. Hatta, özel bir yükümlülüğün kaynağını teşkil eden davranış normları açısından da, nitelik, sıfat farkı gözetilmeksizin, bütün insanlar muhatap olarak telâkki edilmektedirler²⁶.

Toplumun bütün fertlerini **muhatap**²⁷ telâkki eden bu normlara uygun bir davranış, *doğru*²⁸ olan bir davranıştır; bir başka ifadeyle, hukuka ve evleviyetle ahlâka uygun bir davranıştır. Dolayısıyla, bu davranış, müsbet anlamda bir *değer*, *kıymet*²⁹ ifade etmektedir³⁰.

olduğu şeklinde yorumlanamaz (Aksi fikir: ARAL, 16. Akıl ve idrak kavramları hakkında bilgi için bkz. KAUFMANN, Arthur: *Rechtsphilosophie in der Nach-Neuzeit*, 2. Auflage, Heidelberg, 1992, sh. 14 vd.; YAKIT, İsmail: *Semantik Analizler Işığında "Rey" ve "Yakın" Kavramları*, in: Kur'an ve Dil Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2001, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını, sh. 51 vd. [52]).

²⁴ ÖZGENÇ, İzzet: *Kusur Yargısı ve Yaş Küçüklüğü*, in: Facultatis Decima Anniversaria (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye Ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu), İstanbul, 1993, sh. 252; Arm. KAUFMANN, Normentheorie, sh. 105. Normun muhatabı insandır. Bu itibarla, hukuki değerın muhataplığından söz edilemez (Çelişkili açıklamalar için bkz. DEMİRTAŞ, Soner: *Tehlike Suçları*, Ankara, 2023, sh. 140, 162).

²⁵ ÖZGENÇ, Kusur Yargısı, sh. 252; Arm. KAUFMANN, Normentheorie, sh. 125, 138, 164, 281; BLAUTH, Peter: *"Handeln für einen anderen" nach geltendem und kommdem Strafrecht*, Heidelberg, 1968, sh. 33, 69; LENCKNER, Theodor: *Der rechtfertigende Notstand, zur Problematik der Notstandsregelung im Entwurf eines Strafgesetzbuchs (E 1962)*, Tübingen, 1965, sh. 34, dn. 104; MAURACH, Reinhart/GÖSSEL, Karl Heinz/ZIPF, Heinz: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, Teilband 2, 7. Auflage, Heidelberg, 1989, sh. 104/105.

²⁶ ÖZGENÇ, Kusur Yargısı, sh. 252; Arm. KAUFMANN, Normentheorie, sh. 133 vd.; ROXIN, Claus: *Täterschaft und Tatherrschaft*, 4. Auflage, Hamburg-Berlin-New York, 1984, sh. 354; KANGAL, Zeynel T.: *Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu*, Ankara, 2010, 171. Aksi fikir BLAUTH, sh. 60-63.

Herkesi davranış normlarının muhatabı olarak kabul etmekle beraber; bazı davranış normlarında, *belli vasıfları haiz kişiler* (intraeus) *asli muhatap* olarak belirlenmişlerdir. Buna göre, gerçeği, doğruyu söyleme yükümlülüğü, ancak bir vakıa hakkında beş duyusuyla bilgi sahibi olan ve bir hukuki ihtilâfın halli dolayısıyla şahitlik yapan kişinin asli muhatap olduğu bir yükümlülüktür. Keza, velâyet görevi veya kamu görevi gibi bir görevin gereklerine göre hareket edilmesi gerektiği hususundaki yükümlülük, ancak bu görevlerin kendilerine tahmil edildiği kişilerin asli muhatap olduğu yükümlülüktür. Aynı şekilde, meselâ vergi vermek gibi malî yükümlülükler, ancak belli bir miktar malvarlığına sahip kişinin asli muhatap olduğu yükümlülüklerdir.

Her ne kadar bu özel yükümlülüklerin kaynağını teşkil eden davranış normlarının asli muhatabı *belli vasıfları haiz kişiler* iseler de; bu normların ihtiva ettiği emir veya yasaklara riayet edilmesi, toplumdaki hukuk güvenliğinin temini açısından, herkesi alâkadar eden bir husustur. Dolayısıyla, bu özel yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından *haricî kişilerin* (extraneus) tamamen ilgisiz oldukları söylenemez. Haricî kişiler, özel faillik vasfını haiz olmasalar bile, yine de ilgili davranış normunun *talî muhatabı*dırlar. Yani, haricî kişiler, en azından özel faillik vasfını haiz kişinin bu özel yükümlülüğüne aykırı davranışına katkıda bulunmama yükümlülüğü altındadır.

²⁷ "Adressat"

²⁸ "Hak", "Recht"

²⁹ "Wert"

Bu normların ifa ettiği ilk fonksiyon; icraî olsun, ihmalî olsun, insanın belli fiillerinin ahlâken ve hukuken tasvip edilemez olduğu hususunda bir yargıyı ifade etmeleridir. Yani, bu normlar, belli davranış biçimleri hakkında bir *değersizlik yargısının* (veya *menfî, olumsuz anlamda bir değer yargısının*)³¹ oluşumunu sağlamaktadırlar. Bu normlar, kişilerin belli davranışlarının muhteva itibarıyla doğru olmadıklarının, bir *haksızlık*³² teşkil ettiklerinin tespitini sağlarlar³³. Dolayısıyla, davranış normları, toplumda değer telâkkilerinin oluşumunu sağlamaktadır. Bir davranışın bu normlardan birini ihlâl etmesi, bu davranışa haksızlık muhtevasını kazandıracaktır. Bir fiilin kanunla suç (veya genel bir ifadeyle, haksızlık) olarak tarifine takaddüm eden söz konusu normlar sayesinde bu fiilin değerlendirilmesi ni yapmak kabil olacaktır: *Davranış normunun değerlendirme fonksiyonu*^{34,35}.

Fakat, davranış normlarının fonksiyonu, insanın belli davranışları hakkındaki değer yargısından ibaret değildir. Bu normlar, insanlara belli davranışlardan kaçınmayı (yasaklayıcı norm)³⁶ veya belirli olumlu davranışlarda, icraî davranışlarda bulunmayı (emredici norm)³⁷ buyurmaktadırlar: *Davranış normunun buyurucu karakteri*³⁸.

Davranış normları, aynı zamanda, pozitif hukuk düzenlemelerinin adalete uygunluğu açısından, adil olup olmadıkları noktasında denetlenmesi ve değerlendirilmesi imkânını sağlamaktadır³⁹.

Davranış normları, emredici ve yasaklayıcı normlar olmak üzere, ikiye ayrılır.

Emredici normlar, belli bir doğrultuda davranma yükümlülüğünün dayanağını teşkil eder. Belli bir miktar malvarlığına sahip kişiye tahmil edilen, meselâ vergi vermek gibi, mali yükümlülükler, bir vakıa hakkında beş duyusuyla bilgi sahibi olan kişinin bir hukuki ihtilâfın halli dolayısıyla şahitlik yapması halinde gerçeği, doğruyu söyleme yükümlülüğü, velâyet görevi veya kamu görevi gibi bir

³⁰ UCHIYAMA, Minoru: *Das Wertwidrige in der Ethik Max Schelers*, Bonn, 1966, sh. 53 vd.

³¹ “Unwerturteil”

³² Gerçeği, hakkı örtme anlamında *zulm*, “Unrecht”

³³ UCHIYAMA, sh. 63 vd. *Erem’e göre*; “hiç bir şey kendi kendine iyi veya kötü, haklı veya haksız değildir. Bunlar, bir ölçüye bağlıdırlar” (EREM, Genel Hükümler I, 12. bası sh. 13).

³⁴ “Bewertungsfunktion der Norm” Arm. KAUFMANN, Normentheorie, sh. 67; ÖZGENÇ, Kusura Yargısı, sh. 251. Ayrıca bkz. ÇOBANOĞLU, sh. 4, 6; HAFIZOĞULLARI, Zeki: *Ceza Normu, Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni*, Ankara, 1987, sh. 25, 141 vd.; ARAL, sh. 57.

³⁵ Davranış normlarının değerlendirme fonksiyonu dolayısıyla, değerlendirmeyi gerekli kılan hukuki kavramlara “normatif” kavramlar denilmekte, veya kavramın “normatif” özelliğinden bahsedilmektedir (ÇOBANOĞLU, sh. 6-8).

³⁶ “Verbotnorm”

³⁷ “Gebotsnorm”

³⁸ “Befehlscharakter der Norm”

³⁹ ARAL, sh. 46.

görevi icra eden kişinin bu görevin gereklerine göre hareket etmesi gerektiği hususundaki yükümlülüğü, kaynağını emredici normlardan almaktadır.

Yasaklayıcı normlar ise, belli bir davranışta bulunmama yükümlülüğünün dayanağını teşkil eder. Bu normlar, meselâ bir başkasının şahsiyetine, haysiyetine, şerefine tecavüz etmeme, haksız yere bir başkasını öldürmeme, bir başkasının vücut bütünlüğüne, bir başkasının malvarlığına tecavüz etmeme doğrultusunda ki yükümlülükler kaynağı teşkil etmektedir.

Davranış normları, bir *gereklilik*⁴⁰, bir *yükümlülük*⁴¹ ifade etmektedir. İnsanın davranışlarını tayin etme serbestisine ve hürriyetine sahip olması karşısında; bu normlar, kişi açısından bir *mecburiyet*⁴² ifade etmez⁴³. İnsanın kişiliğini geliştirmesi, hayatını ancak davranış normlarına uygun bir şekilde yönlendirmesiyle mümkündür. Yukarıda açıkladığımız üzere; şahsiyetini tekâmül ettirmesi, insan açısından bir *görev*dir. Hayatını bu davranış normlarına göre yönlendirmenin insan açısından bir mecburiyet değil, bir *gereklilik* teşkil etmesinin tabii sonucu olarak; söz konusu davranış normlarına aykırılık yönündeki bir tercih, insan açısından *sorumluluğu*⁴⁴ gerekli kılan bir husustur⁴⁵. İnsanın bu normlardan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde, sorumluluğu söz konusudur. Çünkü, insan, bu yükümlülüklerine uygun hareket etme imkân ve iktidarına sahip olmasına rağmen; iradesini, tercihini aykırı hareket etme yönünde kullanmıştır ve bu nedenle sorumlu olması gerekir⁴⁶.

⁴⁰ “Vücubiyet”, “Sollen”

⁴¹ “Mükellefiyet”, “Pflicht”

⁴² “Müssen”

⁴³ ÇOBANOĞLU, sh. 4/5. Bazı yazarlar, hukukun “cebrî”lik vasfından bahsetmektedirler (GÜRİZ, sh. 75 vd.; ÇAĞIL, sh. 93, 98/99, 103 vd.; ARAL, sh. 66 vd.). Ancak, bununla kastedilen, hukukun esasını teşkil eden davranış normlarına uygun davranılmasının bir mecburiyet teşkil ettiği değildir. Nitekim, *Çağıl*, açıklamalarına devamla, bu normlara uygun davranma açısından “*vücubiyet*” (gereklilik) kavramını kullanmaktadır (sh. 109). Hukukta “cebrî”likten bahsedilirken, normlara aykırılık halinde uygulanması öngörülen müeyyidenin tatbiki ile sınırlı bir açıklamada bulunmaktadır.

⁴⁴ “Mes’uliyet”, “Verantwortung”.

⁴⁵ Sorumluluk, ancak davranış normlarına aykırılıktan, yani hukuka aykırı bir fiilden dolayı söz konusudur. Bu itibarla, hangi gerekçeyle olursa olsun, hukuka uygun bir fiilden dolayı sorumluluktan bahsedilemez. Aksi fikir için bkz. OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, M. Turgut: *Borçlar Hukuku Dersleri*, cilt II, İstanbul, 1991, sh. 1, 3, özellikle 7/8.

⁴⁶ Genel olarak insan, Allah’ın kendisine yüklediği bütün yükümlülüklerin gereklerini yerine getirme istidadına sahiptir. Çünkü, “*Allah insana yerine getirme istidadına sahip olmadığı bir yükümlülük yüklemez*” (Kur’an-i Kerim, Bakara Süresi[2], Ayet 286); Allah, insana ancak verdiği imkanlar ölçüsünde yükümlülük yükler (Kur’an-i Kerim, Talak Süresi[65], Ayet 7). Ancak insan, içinde bulunduğu şahsi veya doğal koşullar nedeniyle, bu yükümlülüklerin gereklerini yerine getiremeyebilir. Bu durumlarda, yükümlülük varlığını devam ettirmekle birlikte; kişinin, bu yükümlülüğün gereklerini yerine getirememesi dolayısıyla sorumluluğu söz konusu değildir (Kur’an-i Kerim, Fetih Süresi[48], Ayet 17).

Bu açıklamalarımız karşısında; kanaatimizce, *gerek ahlâkın gerek hukukun müşterek bir kaynağı* mevcuttur⁴⁷. Bu da, *davranış normlarıdır*. Ahlâk ve hukuk kuralları müşterek bir zemine sahip bulunmaktadır⁴⁸. Bu itibarla, **hukuki olan bir davranış, aynı zamanda ahlâkîdir; ahlâka aykırı bir davranış da, hiçbir zaman hukuken koruma altına alınamaz**^{49, 50}.

⁴⁷ Arth. KAUFMANN, *Recht und Sittlichkeit*, 34. Aksi fikir için bkz. DÖNMEZER, Sulhi: *Cezaî Mesuliyetin Esası*, İstanbul, 1949, sh. 25; DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku*, cilt I, 9. bası, İstanbul, 1985, no. 225.

Alacakaptan, ahlâk ile hukukun alanlarının bugün “birbirinden kesin olarak ayrılmış olduğu” iddiasında bulunmaktadır (ALACAKAPTAN, Uğur: *Suçun Unsurları*, Ankara, 1970, sh. 11/12).

Önder, bu konuda çelişkili ifade kullanmaktadır: “Hukuk ve ahlâk kuralları birbirini kesen iki daireye benzetilebilir. Hukuk kuralları, ahlâk kurallarının hepsini bünyesine almış olduğu düşünülemez. Ahlâk kurallarının birçoğu hem bir ahlâk kuralıdır hem de hukuk tarafından bünyesine alınmıştır. Hukuk ve ahlâk kurallarının iki daire gibi birbirini kestiği ve her iki kuralın birleştiği halin dışında da hukuk kurallarının ahlâk kuralları ile ilişkisinde asgari ahlâk kurallarının varlığı gözlenebilir. Ancak, hukuk düzeni ile ahlâk düzeninin temellerinin farklı olması sonucu, hukuk düzeni her ahlâk kuralını bünyesine alıp bunları hukuk düzeninde geçerli kurallar haline getiremez.” (ÖNDER, Ayhan: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, Cilt I, İstanbul, 1991, sh. 2 vd.).

İçel/Donay’ın bu konuda ileri sürdüğü görüş, sonuçta doğrudur: “Ahlâk normları ile ceza hukuku arasındaki ilişki inkar edilemez. Şöyle ki, toplumun ahlâk normlarına tamamen aykırı ceza hukuku kuralları konulamayacağı gibi, yüksek ahlâkî değerlere aykırı davranışları da ceza hukuku görmezlikten gelemeyiz. Başka bir anlatımla, **ceza hukuku ve ahlâk iç içe iki daire gibi olup, ahlâka ilişkin daire ceza hukuku dairesini de içermektedir**.” (İÇEL, Kayıhan/DONAY Süheyl: *Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I*, 2. bası, İstanbul 1993, sh. 18. Ayrıca bkz. ARTUK, M. Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 13. bası, Ankara, 2019, sh. 176).

Toroslu’nun şu fikirlerine katılmıyoruz: “Ceza hukukunun önemli bir kesimi (politik suçlar, kabahatler gibi) ahlâk ile hiç ilgisi olmayan veya çok az ilgisi bulunan politik zorunluluk veya pratik elverişlilik ölçütlerinden esinlenmektedir.” (TOROSLU, Nevzat: *Ceza Hukuku*, 4. bası, Ankara, Ocak 1998, sh. 17). Toroslu’nun görüşlerine paralel düşünce için bkz. CENTEL, Fatma Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem: *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, 4. bası, İstanbul, Ekim 2006, sh. 83.

⁴⁸ “Tabii hukukun yasakları, aynı zamanda ahlâkın da yasaklarıdır” (HATEMİ, Hüseyin: *Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları*, İstanbul, 1976, sh. 33, dn. 7).

⁴⁹ HATEMİ, Hukuka ve Ahlâka Aykırılık, sh. 33.

Erem, hukukla ahlâk arasındaki ilişkiyle alakalı olarak tamamen katıldığımız şu tesbitlerde bulunmaktadır:

“Ahlâkça kötü bir hareketin hiçbir sosyal zarar doğurmadığına misal bulunamaz. Ahlâkça kötülüklerin arttığı bir toplumda sosyal düzen kaybolur, bundan sonra hürriyette bahsedilemez. ... Eğer bu gün ceza hukuku ile ahlâk ayrı gibi görünüyorsa; bu, **hukuk tekniğinin henüz başarıya tam anlamı ile ulaşamadığındandır**. Halen öyle suçlar vardır ki, suç sayılmalarında ahlâkça zaruret yoktur; buna mukabil, ahlâkça suç olan pek çok hareketlerin henüz kanunca suç sayılmamış olması, izahsız kalmaktadır”. Bu itibarla, “**hukuk tekniği, ahlâkın gereği gibi uygulaması çabası**” olarak anlaşılmalıdır (EREM, Genel Hükümler I, 12. bası, sh. 14, ayrıca, sh. 63/64).

Aral, bir taraftan “ahlâk, bireyin kendi vicdanının ürünüdür. Ahlâk alanında bir iç kanun koymadan ... söz edilir. Ahlâk normlarının, onları koyan bireyin vicdan ve zihniyetinden başka bir kanun koyucusu yoktur” derken (sh. 74); diğer taraftan ahlâkın “**birey üstü objektif de-**

Bu müşterek zemine karşılık; ahlâkla hukuk arasında bir farklılık bulunmaktadır. Davranış normlarına aykırı her davranış, ahlâka aykırılık arzeder ve dolayısıyla, “ahlâkî” sorumluluğu gerektirir. Hukukun alanı ise, davranış normlarına aykırılığın hukuk toplumunda hakim olan düzeni bozucu bir boyuta ulaştığı anda başlamaktadır. Meselâ mücerret yalan, doğru sözlülüğü emreden davranış normlarına ve dolayısıyla, ahlâka aykırı bir davranıştır. Ancak, yalanın bir başkasının hukukunu etkileyici bir sonuç icra edebileceği durumlarda, hukukun müdahale alanı başlamaktadır. Yani, çeşitli yalan beyan tarzları itibarıyla, iftira, suç tasnii, yalan şahitlik, hile, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi haksızlıkların gerçekleşmesi halinde, hukukun müdahale edebileceği bir norma aykırılık mevcut olacaktır⁵¹.

ğerler düzenine ilişkin” olduğundan bahsetmektedir (aynı sahife). Ahlâk normlarının kaynağı konusunda bir çelişkiyi ifade eden bu açıklamaların yanısıra; *Aral*, hukukla ahlâk arasındaki farkı ortaya koymaya çalışırken, “kanuna (hukuka) uygunluk (legalite) ile ahlâka uygunluğun (moralite’nin) birbirinden ayrı olduğu sonucu”na varmaktadır. *Aral*’a göre; “hukuka uygun bulunan bir fiilin zorunlu olarak ahlâka da uygun bulunması gerekmez” (sh. 72). Keza, *Aral*, “hukukta sorumlu olunan makamın dışta, ahlâkta ise içte bulun”duğundan bahsetmektedir (sh. 75). “Hukukun idesi ve idealinin adalet olmasına karşılık ahlâkın amacı(nın), ideali(nin) iyi’yi (hayrı) gerçekleştirmek” olduğunu söyleyen *Aral*’a göre; “adalet ile iyi arasındaki ayırım da, adaletin toplumsal bir değer olmasında, onun doğru, herkesi hoşnut eden, yetkin bir toplumsal düzeni deyimlemesinde, buna karşılık, ahlâkın ideali olan iyi’nin ise, tek tek insanla, onun yetkinliği ile ilgili bir değer oluşunda gösterilir” (sh. 77). Fakat, yazar, aynı eserde doğru olarak şu tespitlerde bulunmaktadır: “... adalet de iyidir, iyi bir şeydir ve bu yüzden aynı zamanda ahlâkî bir kavramdır. ... *adaletin gerektirdiği toplumsal yaşam*, kişisel yaşamın bir yanındır ve bu yan, *temelinde ahlâk normlarına tabidir*” (sh. 81).

⁵⁰ Ahlâkın bireysel veya sosyal ahlâk, genel ve toplumsal ahlâk diye bir ayrıma tabi tutulması, doğru değildir. Bu anlayış, esasında ahlâkî değerleri örseleyen bir yaklaşımdır. Ahlâkî değerlerin hepsinin sosyal hayatla ilişkisi bulunmaktadır. Sosyal hayatla ilişkisi bulunmayan bir ahlâk kuralından söz edilemez.

Ahlâk kuralları, yere, zamana, kişiye ve topluma göre değişkenlik arz etmez. Örneğin cinsel arzuların tatmin amacına matuf birtakım davranışların alenen işlenmesi, bazı toplumlarda hoşgörü ile karşılanabilir. Ancak, bu hoşgörülü yaklaşım, ilgili davranışın ahlâka uygunluğunun kabulü anlamına gelmemektedir.

Bir başkasının hukuku üzerinde etkili olsun veya olmasın, yalan söylemek, her toplumda ve her zaman ahlâka aykırı bir davranış olarak değerlendirilmiştir. Belirli koşullarda yalan söylemenin mazur karşılanması söz konusu olabilirse de bu koşullar, yalan söylemenin ahlâka uygun kabul edilmesini gerektirmez.

Ahlâka aykırılığın sorumluluğu gerektirebilmesi için, bunun münhasıran kasten işlenmesi gerektiği fikri de sorunludur.

Hırsızlık, hukuka ve evleviyetle ahlâka aykırı bir davranıştır. Bunun hem özel hukuk hem de ceza hukuku sorumluluğunu gerektirdiği tartışmasızdır.

Bir başkasının malvarlığına kasten zarar verme fiili, kasten işlendiğinde hem özel hukuk hem de ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmekle birlikte, bu zarar neticesine dikkatsiz ve özensiz davranışla sebebiyet verilmesi, sadece özel hukuk sorumluluğunu gerektirir. Bu itibarla, bir başkasının malvarlığına dikkatsiz ve özensiz davranışla zarar verilmesinin, ahlâka aykırı olmadığı ve tersi ifadeyle, ahlâka uygun olduğu söylenemez.

⁵¹ Bu hususta bkz. ERMAN, Sahir: *Sahtekârlık Suçları*, 4. bası, İstanbul, 1981, no. 2 vd.

Keza, davranış normlarıyla yasaklanmış bulunan bir cinsî ilişki biçimi, dokunulmaz, mahrem bir alan içerisinde, kişilerin özel hayatı çerçevesinde cereyan ettiği sürece, ahlâka aykırı ve fakat hukukten müdahale edilemeyen bir davranış olarak telakki edilmelidir. Ancak, bu aykırı davranış biçiminin özel hayatın çerçevesi dışında, dokunulmaz, mahrem alanın dışında gerçekleşmesi halinde, bir başka ifadeyle, aleniyet kazanması halinde, hukukten müdahale etme imkânı doğacaktır^{52,53}.

Belli bir insan davranışının hukukun müdahale alanı dışında kalması, bu davranışın hukukten değerlendirme dışı kaldığı anlamına gelmez. Meselâ, kumar borcunun ifası hususunda kamu gücünün kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Bu nedenle, kumar borcu “*tabii borç*” olarak nitelendirilmiştir. Ancak, bu durum, hukukun kumar oyununu değerlendirme dışı bıraktığı anlamına gelmez. Bu nedendir ki, kumar, ahlaken tasvip edilmediği gibi, hukuka uygun bir davranış da değildir.

Demek ki, hukukla ahlâk arasında sıkı bir ilişki mevcuttur⁵⁴. Pozitif hukuk, ahlâkî yükümlülüklerin yerine getirilmesine insanı *meccur* eden değil; bunların yerine getirilmesini insana *mümkün* kılan bir araç olarak anlaşılmalıdır. Böylece, hukukun amacı ahlâkî bir temele oturtulmuş olmaktadır: Hukuk, insan şahsiyetinin serbestçe tekâmülünü mümkün kılacak ve bunun şartlarını teminat altına alacaktır⁵⁵. Netice olarak, hukukla ahlâk arasında hiçbir zaman bir çelişkinin mevcudiyetinden bahsedilemez^{56,57,58}.

⁵² Hukukla ahlâk arasındaki müştereklik hakkında bkz. Arth. KAUFMANN, Recht und Sittlichkeit, 28 vd. *Hatemi*, Doçentlik Tezinde "Hukuk, asgarî bir ahlâklılık istemektir" derken ve hukuk ile ahlâk arasındaki farkı müeyyideye indirirken (Hukuka ve Ahlâka Aykırılık, sh. 27); bizimle aynı hareket noktasını benimsemiş bulunmaktadır.

⁵³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Cinsel Suçlar Bağlamında, Kur'an Hükmüleri Üzerine Bir Değerlendirme*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXII, Temmuz 2018, sayı 3, sh. 57 vd.

Doktrinde bir görüş, aleniyet şartı aranmaksızın, reşitler arasında karşılıklı rıza ile gerçekleşen cinsel ilişkinin de suç olarak tanımlanması gerektiğini savunur: ARTUK/GÖKCEN/ALŞA-HİN/ÇAKIR, Genel Hükümler (13), sh. 175, dn. 158.

⁵⁴ Arth. KAUFMANN, Recht und Sittlichkeit, 17. Bu ilişki, **aynı merkeze sahip ve fakat çapları birbirinden farklı olan iki daireye** benzetilmektedir. Bunlardan çapı büyük olan ahlâkı, küçük olan ise hukuku ifade etmektedir.

⁵⁵ Arth. KAUFMANN, Recht und Sittlichkeit, 17/18.

⁵⁶ Arth. KAUFMANN, Recht und Sittlichkeit, 28 vd., 31 vd. Hukukla ahlâk ilişkisi açısından ayrıca bkz. HATEMİ, Hukuka ve Ahlâka Aykırılık, sh. 34, dn. 8.

⁵⁷ Ahlâkın ölçütlerinin, yaşanan kültür ortamına göre, bir başka ifadeyle, yere, zamana ve hatta kişiye göre değişkenlik arzedeceği hususundaki görüş (DÖNMEZER, Sulhi: *Ceza Hukuku, Özel Kısım, Genel Adab ve Aile Düzenine Karşı Cürümler*, 5. bası, İstanbul, 1983, no. 183; ERMAN, Ragıp Barış: *Yanılmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, sh. 128), kanaatimizce **doğru değildir**.

⁵⁸ Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun **6.7.2018** tarihli ve K. 2018/7 sayılı Kararında (RG: 8 Aralık 2018 / 30619), 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 185. maddesinde (f. 3) hüküm altına alınan **sadakat yükümlülüğünün, sadece evli eşler bakımından** hukuki sonuç doğurduğu kabul edilmektedir. Söz konusu Karara göre, evli eşlerden biriyle duygusal ve hatta cinsel

ilişkide bulunan üçüncü şahıs, sadakat yükümlülüğünün muhatabı değildir. Bu itibarla, söz konusu yükümlülüğünden, eşini aldatan kişiyle örneğin cinsel ilişkide bulunan üçüncü şahıs bakımından sorumluluğu gerektiren bir sonuç çıkarılamaz. Büyük Genel Kurul kararındaki ifadelerle göre;

“... evlilik birliğinin tarafı olmayan ve dolayısıyla sadakat yükümlülüğü bulunmayan üçüncü kişinin eşler arasındaki evlilik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerle uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.”

“... üçüncü kişinin eyleminin herhangi bir koruma normunu ihlal ettiği söylenemeyeceğinden bu yönden hukuka aykırı kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.”

“Eşlerden biri yalnızca diğer eşten sadakat yükümlülüğüne uygun davranmasını talep edebilir. Üçüncü kişinin sadakat yükümlülüğünün bulunmaması nedeniyle, evli eşle birlikte olan üçüncü kişinin bu davranışının diğer eşin kişilik haklarına doğrudan bir saldırı niteliğinde olduğu söylenemez.”

“... üçüncü kişinin cinsel birliktelik yaşadığı eşi karşı herhangi bir hukuka aykırı fiili bulunmamaktadır ki, aynı fiil ile diğer eşin de kişilik haklarına saldırıldığından bahsedilsin ...”

“Evli bir kişiyle birlikte olan üçüncü kişinin eyleminin ahlâka aykırı olduğunu söylemek mümkündür ...”

Büyük Genel Kurul, söz konusu kararda, bir fiilin **ahlaka aykırı olmakla birlikte hukuka aykırı olmayabileceğini** kabul etmektedir. Oysa 6708 sayılı Borçlar Kanununun 49. maddesinin ikinci fıkrasında,

“Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlâka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümle, ahlaka aykırı fiili yasaklayan bir pozitif hukuk kuralının bulunmayabileceğine işaret edilmektedir. Ancak bu hüküm, ahlaka aykırı bir fiili yasaklayan bir pozitif hukuk kuralının bulunmamasından, bu fiilin hukuka aykırı olmadığı sonucu çıkarılacak şekilde yorumlanamaz. Oysa Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun söz konusu kararında;

*“Genel ve toplumsal ahlâk kurallarına aykırı bir fiille başkasına zarar verilmesi durumunda **fiil hukuka aykırı olmasa bile** TBK’nın 49. maddesinin 2. fıkrasına göre tazminat talep edilebilecektir.”*

ifadesine yer verilmiştir. İlginçtir ki, söz konusu kararlarda bir taraftan “aldatılan eş” ibaresi kullanılmakta, diğer yandan ise, buna rağmen “**aldatılan bu eşin kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem**”in varlığı kabul edilmemektedir.

Büyük Genel Kurul’a göre;

“... üçüncü kişinin fiilinin haksız fiil olarak nitelendirilebilmesine olanak bulunmadığından sadece aldatma fiiline iştirak etmesi nedeniyle, aldatan eşle birlikte TBK’nın 61. maddesi çerçevesinde müteselsilen sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir.”

Ancak, Büyük Genel Kurul kararında “evli olduğunu bilerek bir kişiyle birlikte olan üçüncü kişinin ... evlilik birliğine karşı göstermesi gereken özen ve saygıyı göstermemiş olması”ndan söz edilerek, hukuka aykırılık bağlamında dikkate alınması gereken bazı doğru ifadelerle de yer verilmiştir. Buna rağmen Büyük Genel Kurul, üçüncü kişinin fiili bağlamında “**haksız fiile ilişkin genel koşulları taşımayan eylem**”den söz edilmektedir. Üçüncü kişinin fiili bağlamında hukuka aykırılıktan söz edebilmek için, “*aldatılan eşin konut dokunulmazlığını ihlal etmesi, özel yaşamına müdahale etmesi, sır alanına girmesi, ele geçirdiği bazı özel bilgileri ifşa etmesi, kullandığı söz ve diğer ifadeler ile onur ve saygınlığını zedelemesi*” gerekmektedir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki, bu üçüncü kişinin eşi tarafından cinsel sadakatsizliğe uğrayan -aldatılan- eşe karşı aldatan eş ile birlikte tazminat sorumluluğunun olup olmaması, bir ceza hukukçusu olarak bizi ilgilendirmemektedir. Bizi ilgilendiren husus, söz konusu **fiilin, hukuka aykırı olduğunun kabul edilmemesidir**.

Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Davranış Normları Teorisi, Hukuk ve Ahlak İlişkisi*, in: TÜBA Günce, sayı 59, Ocak 2019, sh. 30 vd.

İnsan, davranış normlarından kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranışta bulunması halinde, *sorumlu* olacaktır. Yani, insana bu yükümlülüklerine neden aykırı hareket ettiği *sorulacaktır*. Bu durum karşısında; *sorumluluğun* mutlaka *bir mercie karşı olması* gerekir. Kişinin yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde sorumluluk, öncelikle ve her halde bu davranış normlarının buyurana karşı olacaktır⁵⁹. Yukarıda da izah ettiğimiz gibi, davranış normlarına bazı aykırılık hallerinde bir diğer insanın hukuku ihlâl edilmemiş olabilir. Davranış normlarına bu gibi aykırılık halleri, pozitif hukukun düzenleme alanı dışında tutulmaktadır. Bu gibi hallerde sadece "*ahlâkî sorumluluk*" mevcuttur.

Davranış normlarına aykırılık bir başkasının hukukunu ihlâl ediyorsa; sorumluluk, *aynı zamanda* bu kişiye karşı olacaktır: Genel anlamda "*hukuki sorumluluk*". Bu sorumluluk, belli bir kişinin hukukunun ihlâl edilmesi dolayısıyla, *bu kişiye karşı* olabileceği gibi (*özel hukuk sorumluluğu*); davranış normundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâlinin hukuk toplumundaki düzenin bozulması tehlikesini oluşturduğu hallerde, *toplumun bütün fertlerine karşı* da söz konusu olacaktır (*kamu hukuku sorumluluğu*).

Davranış normlarıyla insana tahmil edilen yükümlülüklerle aykırı bir davranış gerçekleştirildiği zaman, bu haksızlığı gerçekleşmemiş hale irca etmek artık mümkün değildir. Ancak, bu yükümlülüklerle aykırılık dolayısıyla gerçekleşen haksızlık karşısında, hukuk düzeninin idamesi amacıyla, bazı *yaptırımlar* uygulamak gerekir. Bu itibarla, **yaptırım, insanın muhatap olduğu davranış normlarından kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranışının gerekli kıldığı hukuki sonuçtur.** Gerçekleşen haksızlık dolayısıyla, hukuk düzeninin kişiler arasında oluşturduğu hukuki denge bozulmuştur. Yaptırım uygulanmasıyla güdülen genel amaç, bu dengenin yeniden tesis edilmesidir. Her bir somut olaya ilişkin olarak yaptırım uygulanmasıyla, toplumu oluşturan fertler nezdinde, *haksızlık*⁶⁰ karşısında *hakkın*⁶¹ mutlak üstünlüğü ve mutlak geçerliliği bir defa daha pekiştirilmektedir⁶².

Bu konu, Türkiye Bilimler Akademisi'nin "Akademi Konferansları" çerçevesinde, 28 Şubat 2019 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde konferans olarak verilmiştir.

⁵⁹ İnsan, gerçekleştirdiği bütün haksızlıkların karşılığını, Rabbi huzurunda eksiksiz olarak görecektir (Kur'an-i Kerim, Nahl Süresi[16], Ayet 111). Hesap günü, adaletle hüküm verme günü, doğruyu yanlıştan ayırd etme günü, ayrışma günü (Kur'an-i Kerim, Saffât Süresi[37], Ayet 21; Duhan Süresi [44], Ayet 40 vd.; Mürselât Süresi[77], Ayet 13, 14, 38; Nebe' Süresi[78], Ayet 17) insanın icrai veya ihmali bütün davranışları sergilenecek, ortaya dökülecek ve önüne konulacaktır (Kur'an-i Kerim, Teğâbün Süresi[64], Ayet 7; Kıyamet Süresi[75], Ayet 13; Tekvir Süresi[81], Ayet 7; Târik Süresi[86], Ayet 9).

Davranış normlarının buyuranının özellikleri ve insan ile yaratıcısı arasındaki ilişki hakkında bilgi için bkz. YÜCEL, Hasan-Âli: *Allah Bir*, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1961, sh. 7 vd.

⁶⁰ "Unrecht", "şerr", "kötülük", "Böse".

⁶¹ "Recht", "hayır", "iyilik", "Gute".

⁶² PAPA XII. PIUS'un 3 Ekim 1952 tarihinde Roma'da tertiplenen VI. Milletlerarası Ceza Hukuku Kongresinde yaptığı konuşma, in: JZ 1953, sh. 771 vd.

Kişiler davranış normlarına uygun davranma doğrultusunda bir mecburiyetle karşı karşıya değilse de; bir başkasının sahip olduğu değerleri, bir başkasının hukukunu korumaya matuf davranış normlarından kaynaklanan yükümlülüklerle aykırı davranış halinde; bu aykırı davranışın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaya veya en azından azaltmaya yönelik yaptırımların uygulanması açısından bir *mecburiyet* söz konusudur. Bu nedenledir ki; hukukun "cebrî"lik vasfından söz edilmektedir⁶³. Bir başka ifadeyle; hukuka uygun davranmak mecburiyetinde olmayan insan; hukuka aykırı davranması halinde, bu aykırılığın sonucu olan yaptırımlara katlanmak mecburiyetinde kalacaktır.

Yaptırımı, genel hatlarıyla iki kısma ayırabiliriz. Birinci kısımda mütalâa edeceğimiz yaptırım, *mağdurun*, bir *haksızlığa maruz kalan kişinin*, *haksızlık dolayısıyla kadre uğrayan kişinin*, bu *mağduriyetini gidermeyi* amaçlamaktadır.

Haksızlığa uğrayan kişinin bu mağduriyetini giderme de iki şekilde mümkündür.

Önce, davranış normuyla kişiye tahmil edilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde; yaptırım olarak kişi bu yükümlülüğüne uygun hareket etmeye mecbur edilebilir. Bir başkasıyla akdî ilişkiye giren kişi, sözleşmeyle kendisine tahmil edilen yükümlülüklerini, ahde vefa ilkesine aykırı olarak, yerine getirmemesi halinde, hukuken bu yükümlülüklerine uygun hareket etmeye mecbur edilebilir: *Aynen ifa*. Meselâ kira ilişkisinde kiracı, kira bedelini öngörülen zamanda veya miktarda ödemediği takdirde, bu bedeli ödemeye mecbur edilebilir.

Aynen ifanın mümkün olmadığı durumlarda, meselâ haksız fiil karşılığında *tazminat* ödenmesi de, bu tür bir yaptırımdır. Bu tür bir yaptırımla güdülen asıl amaç, haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyetini gidermektir; bu haksızlığın mağdur üzerindeki etkilerini mümkün olduğunca telâfi etmektir. Bu tür müeyyidenin haksızlığı gerçekleştiren üzerinde bir etki icra etmesi, talî bir husustur.

İkinci kısımda mütalâa edeceğimiz yaptırımlar ise, haksızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde doğrudan etki icra ederler. Yani, bu tür yaptırımla güdülen asıl amaç, *haksızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde belli hukuki sonuçlar doğurması, bu kişiye belli etkilerde bulunmasıdır*.

Bu yaptırımları da iki grupta mütalâa edebiliriz.

Birinci grupta mütalâa edeceğimiz yaptırım ile güdülen asıl amaç, suç teşkil eden bir haksızlığı gerçekleştiren kişinin, bu suçu işlemek dolayısıyla içinde bulunduğu kusurluluk durumundan ibra olmasını sağlamaktır⁶⁴. Biz, buna *teknik anlamda ceza* demekteyiz. Cezanın birincil amacı, *kefarete* teşkil etmesidir. Bir başka ifadeyle, kişinin işlediği suçtan dolayı kusurunun örtülmesidir; kısacası,

⁶³ GÜRİZ, sh. 75 vd.; ÇAĞIL, sh. 93, 98/99, 109 vd.

⁶⁴ Ancak, *Önder*, cezanın uygulanmasına duyulan gerekliliği; Devletin korunmasına, Devletin varlığını idame ettirmesine duyulan ihtiyaçla izah etmeye çalışmaktadır (ÖNDER, Ayhan: *Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, cilt III, İstanbul, 1989, sh. 8, 14).

kişinin resosyalize edilmesidir⁶⁵. Böylece, belli bir cezaya mahkûm olan kişi, bu cezanın infazıyla, önce, işlediği suçtan dolayı sorumluluğun kendi uhdesinde olduğunun şuuruna, bilincine kavuşmalıdır. Cezanın infazıyla kişi, gerçekleştirdiği haksızlıktan dolayı sorumluluk altında olduğunu aktüel bir şekilde hissedecek ve böylece, kusurundan ibra olacaktır^{66,67,68}.

⁶⁵ “Qeffare”. Hemen belirtmemiz gerekir ki; kefarete kavramı, Türk ceza hukukçuları tarafından bizim işaret ettiğimizden farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Kefarete kavramına suç teşkil eden fiil karşısında faile ıztırap verilmesi, acı çektilmesi şeklinde bir anlam yüklenmiştir. Bu anlamıyla “kefarete” kavramı, özellikle *Kant*’ın cezaya ilişkin felsefi görüşlerinde yer alan “*Vergeltung*” (misliyle mukabele, misilleme), “retribution” (geri ödeme) kavramı karşılığında kullanılmaktadır. Bkz. DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku*, cilt II, 8. bası, İstanbul, 1983, no. 1310 vd.; ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 9 vd.; aynı yazar, *Ceza Hukuku Dersleri*, İstanbul, 1992, sh. 478 vd.; ÖZTÜRK, Bahri: *Ceza ve Emniyet Tedbirleri Hukuku*, İzmir, 1992, sh. 231. Ayrıca bkz. AKTAŞ, Sururi: *Cezalandırmanın Amacı*, in: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XIII, sayı 1-2, Haziran 2009, sh. 15 vd.

⁶⁶ **Ceza, suç işleyen kişi açısından bulunulan kusur yargısının maddi bir muhteva kazanmasıdır, müşahhaslaşmasıdır** (Arm. KAUFMANN, Normentheorie, sh. 228). Bu itibarla, **ceza, kişinin işlediği haksızlık dolayısıyla, yükümlülüklerine aykırı davranması dolayısıyla, içinde bulunduğu kusurluluk durumundan ibra olmasına, bu suretle -kural olarak- kişinin tekrar topluma kazandırılmasına hizmet etmelidir**. Bu hususta bkz. BOCKELMANN, Paul: *Vom Sinn der Strafe*, in: Heidelberger Jahrbücher V, sh. 25; aynı yazar: *Schuld und Sühne*, Göttingen, 1957 (30 sahifeden ibaret bütün eser); SCHMIDHAUSEN, Eberhard: *Vom Sinn der Strafe*, 2. Auflage, Göttingen, 1971, sh. 43 vd.; WALDER, Hans: *Die Vernehmung des Beschuldigten*, Hamburg, 1965, sh. 18; RÖSSNER, Dieter: *Autonomie und Zwang im System der Strafrechtsfolgen*, in: Festschrift für Jürgen Baumann, Bielefeld, 1992, sh. 269 vd.

Cezanın asıl amacının -kural olarak- **müsbet anlamda özel önleme** olduğu, suç işleyen kişinin yeniden topluma kazandırılması, toplum açısından zararsız ve güvenilir bir kişi haline getirilmesi olduğu hususundaki telâkkimiz hakkında bkz. Arth. KAUFMANN, Schuldprinzip, sh. 116 vd., 127 vd., 201 vd., 208 vd.; aynı yazar, Recht und Sittlichkeit, sh. 44; aynı yazar: *Dogmatische und kriminalpolitische Aspekte des Schuldgedankens im Strafrecht, ein Beitrag zur Strafrechtsreform*, in: Juristenzeitung, 1967, sh. 553 vd. (özellikle sh. 556 vd.); aynı yazar: *Schuldprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz*, in: Festschrift für Richard Lange, Berlin, 1976, sh. 27 vd.; aynı yazar: *Schuld und Prävention*, in: Festschrift für Rudolf Wassermann, Darmstadt/Neuwied, 1985, sh. 889 vd. (893 vd.); aynı yazar: *Unzeitgemäße Betrachtungen zum Schuldgrundsatz im Strafrecht*, in: Jura, 1986, sh. 225 vd. (229 vd.). Ayrıca bkz. STRATENWERTH, Günter: *Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips*, Heidelberg/Karlsruhe, 1977, özellikle sh. 28 vd.

Ancak, günümüz ceza hukuku doktrininde önemli ölçüde taraftar bulan diğer bir telâkki ise, cezanın asıl amacının **müsbet anlamda genel önleme** olduğunu iddia etmektedir. Bu telâkkiye göre, cezalandırmak suretiyle kişinin işlediği haksızlıktan ibra olmasını bekleyemeyiz. Bu, ahlâki bir meseledir. Suç işleyen ve bu nedenle kusurlu telâkki edilen kişiyi cezalandırmakla güdülen asıl amaç; ihlal edilen davranış normlarının uyulması, riayet edilmesi gereken buyruklar olduğu hususunda toplumun diğer fertleri nezdinde bir uyarı, ikaz meydana getirmektir: **Müsbet anlamda genel önleme**. Bu anlayıştaki yazarlar, cezanın amacının genel anlamda korkutuculuk (**menfi anlamda genel önleme**) olduğu iddiasını doğru bulmamaktadırlar. Bu hususta bkz. NOLL, Peter: *Schuld und Prävention unter dem Gesichtspunkt der Rationalisierung des Strafrechts*, in: Beiträge zur gesamten Strafrechtswissenschaft, Festschrift für Hellmuth Mayer, Berlin, 1966, sh. 219 vd. (229 vd.); ROXIN, Claus: *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe*, in: JuS 1966, sh. 377 vd. (381 vd.); aynı yazar: *Kriminalpolitische Überlegungen zum Schuldprinzip*, in: MschrKrim 56(1973), sh. 316 vd (320 vd.); aynı yazar: *Was bleibt von der Schuld im Strafrecht übrig?*, in: SchwZStr 104(1987), sh. 641 vd. (652 vd.); aynı yazar: *Das Schuldprinzip im Wan-*

Bazı durumlarda, hukuka aykırı davranışın gerçekleştirilmesi sebebiyle, bu aykırılığı gerçekleştiren kişi, bu hukuka aykırı davranışın konusu, bu fiilin işlenmesiyle elde edilen ekonomik menfaat ve hatta bu davranışın gerçekleştirilmesinde kullanılan araç hakkında bir yaptırım olarak **güvenlik tedbiri** uygulanabilmektedir. Bu bakımdan, güvenlik tedbiri, gerek haksızlığı gerçekleştiren kişinin kendisini gerek toplumu belli zarar tehlikelerinden korumak amacına yönelik bir yaptırımdır. Güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için gerçekleşen haksızlık dolayısıyla kişinin kusurlu telâkki edilmesi zorunlu değildir⁶⁹. Cezanın tatbiki açısından gerçekleşen haksızlık dolayısıyla kişinin kusurlu telâkki edilmesi zorunlu ise de; güvenlik tedbiri tatbiki açısından bu zaruret aranmaz. Bu itibarla, gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla kişi kusurlu telâkki edilmese bile, muhtemel zarar tehlikelerine karşı gerek kendisini gerek toplumu korumak amacıyla, güvenlik tedbiri uygulanabilir.

Her ne kadar davranış normlarına (yani hukuka ve evleviyetle, ahlâka) aykırı bir fiil gibi müşterek bir dayanağa sahip iseler de; mahiyetleri ve hizmet ettikleri amaçlar birbirlerinden farklı olan bütün bu yaptırımlar, birbirlerinden bağımsız olarak uygulanabilirler. Bu itibarla, *non bis in idem* kuralının bu müeyyideler arasındaki ilişkilerde tatbik kabiliyeti yoktur⁷⁰.

del, in: Strafrechtigkeit, Festschrift für Arthur Kaufmann, Heidelberg, 1993, sh. 519 vd.; aynı yazar: "Schuld" und "Verantwortlichkeit" als strafrechtliche Systemskategorien, in: Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft, Festschrift für Heinrich Henkel, 1974, sh. 171 vd.

Cezanın müsbet anlamda genel önleme amacına matuf olduğu düşüncesinde olan *Jakobs'a* göre, kusur maddi muhtevadan yoksundur. Ancak cezalandırmayla güdülen söz konusu genel önleme amacı, kusura maddi muhteva kazandıracaktır (JAKOBS, Günther: *Schuld und Prävention*, Tübingen, 1976, sh. 14, 24, 33; aynı yazar: *Strafrechtliche Schuld ohne Willensfreiheit*, in: *Aspekte der Freiheit* [herausgegeben von Dieter Heinrich], Regensburg, 1982, sh. 69 vd. [72]; aynı yazar: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, die Grundlagen und die Zurechnungslehre, Lehrbuch*, 1983, sh. 384 vd.). *Jakobs'a* göre, kişi, kusurlu olduğu için değil; bilakis, ictimâî bakımdan cezalandırılmasına gereklilik duyulduğu için cezalandırılmaktadır. Bir başka ifadeyle, kişi açısından kusurluluk yargısında bulunulabilmesi için, önce kişinin cezalandırılmasına ictimâî bakımdan gerek duyulması lazımdır. *Jakobs'un* bu fikirlerine karşı yöneltilen en esaslı eleştiri; suç işleyen kişinin ictimâî bakımdan cezalandırılmasına duyulan gerekliliği, hareket noktası olarak kabul edişine dayanmaktadır.

⁶⁷ Bu nedenledir ki; ceza tatbiki için, kişinin mutlaka kusurlu olması gerekir. Kusur, cezalandırmanın vazgeçilmez şartını oluşturmaktadır (*nulla poena sine culpa* = kusursuz ceza olmaz).

⁶⁸ Bu konuda bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *İnsan Öldürme İle İlgili Kur'an Hükümlerinin Günümüz Ceza Hukuku Düşüncesine Aktarılması*, in: Dr.Dr.h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan, Editörler: F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoğlu, A. Sözüer, F. Turhan, Ankara, Mayıs 2018, sh. 503 vd. Bazı yazarlar, taksirli suçlar bağlamında bir ahlaka aykırılıktan söz edilemeyeceği düşüncesindedirler: ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, Genel Hükümler (13), sh. 174, 176.

⁶⁹ Aynı mealde ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 20/21, 101.

⁷⁰ ÖZGENÇ, İzzet: *Müessir Bir Çevre Koruması ve Hukuk, Mer'î Hukukun Değerlendirilmesi*, in: Türk Devletleri Arasında 1. İlmî İşbirliği Konferansı (22-24 Haziran 1992-Lefkoşe, KKTC), Tebliğler, İstanbul, 1992, sh. 427; ÖZAY, İl Han: *İdarî Yaptırımlar*, İstanbul, 1985, sh. 62-64.

Ekskurs 1. Fuhuş ve Hukuk

I. Yukarıda açıkladığımız gibi, ahlâk ve hukuk kuralları, müşterek bir zemine sahip bulunmaktadır. Bu itibarla, ahlâka aykırı bir davranış, hiçbir zaman hukuki korumaya altına alınamaz. Bu bağlamda fuhuş, önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Fuhuş, bir kişinin menfaat karşılığında kendi vücudu üzerinde başkalarının cinsel arzularını tatmin amacına yönelik tasarrufta bulunmasına katlanmasıdır⁷¹.

Ahlaken tasvip edilmeyen ve dolayısıyla, insan onuruyla bağdaşmayan fuhşun önlenmesi için, milletlerarası alanda çeşitli sözleşmeler imzalanmakta ve devletler kendi iç hukuklarında düzenlemeler yapmaktadırlar.

II. Türkiye, fuhuşla mücadele ile ilgili bazı milletlerarası sözleşmelere taraf olmakla, bu konuda bazı yükümlülükler üstlenmiştir.

1) Fuhuşla mücadele konusunda milletlerarası alanda kabul edilen ilk sözleşme, **18.5.1904** tarihli “**Beyaz Kadın Ticaretinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**”dir.

Söz konusu Sözleşme, taraf devletlere “*fuhuş amacıyla kadın veya kızların yabancı bir ülkeye temin*”ine ilişkin **bilgilerin paylaşımı** hususunda **yükümlülük** yüklemektedir (m. 1).

Ancak bu Sözleşme, taraf devletlere fuhşun yasaklanmasına ve fuhşa aracılık eden kişilerin cezalandırılmasına yönelik bir yükümlülük yüklememektedir.

Sözleşmede, fuhşa sürüklenen kişiler, “*kadın ve kızlar*” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Sözleşmede, “*gayri ahlaki bir hayat sürmek zorunda kalan kadın ve kızlar*” (“*women and girls destined for an immoral life*”) ibaresine yer verilmiştir (m. 2).

2) Milletlerarası alanda ikinci sözleşme ise, **4.5.1910** tarihli “**Beyaz Kadın Ticaretinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**”dir.

İlk defa bu Sözleşme ile taraf devletlere fuhşa aracılık etme fiillerini **suç** olarak tanımlama yönünde bir yükümlülük yüklenmiştir:

“*Başkalarının cinsel arzularını tatmin etmek için, fuhuş maksadıyla, küçük bir kızı veya kadını, kendi rızası olsa bile, kullanan, kaçıran veya baştan çıkaran kimse, suçu oluşturan muhtelif fiiller farklı memleketlerde işlenmiş olsa da cezalandırılacaktır*” (m. 1).

Bu Sözleşmede de fuhşa sürüklenen kişiler, “*kız ve kadınlar*” olarak belirlenmiştir.

⁷¹ Bu hususta bkz. TCK’nın “Fuhuş” suçunu düzenleyen 227. maddesinin gerekçesinde yer alan açıklamalar. Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “Fuhuş ve Hukuk, Anayasa Mahkemesinin 18.10.2017 tarihli ve 2014/19152 numaralı Bireysel Başvuru Kararının Değerlendirilmesi”, in: Dr.Dr.h.c.Silvia Tellenbach’a Armağan (Editörler, F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoglu, A. Sözüer, F. Turhan), Ankara, Mayıs 2018, sh. 483 vd.)

Söz konusu Sözleşmede, fuhşa aracılık fiillerinin suç olarak tanımlanması bağlamında fuhşa sürüklenen, fuhşuna aracılık edilen kişilerin yaşı ile ilgili olarak bir ayırıma yer verilmiştir.

Buna göre, fuhşa sürüklenen, fuhşuna aracılık edilen kadının “küçük” olması halinde, bu kişinin fuhşa yönelik olarak açıklamış bulunduğu rızanın hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır (m. 1).

Sözleşmenin ikinci maddesi hükmü karşısında, birinci maddedeki “küçük” ibaresinden, **henüz reşit olmamış kadın** anlaşılmak gerekir.

Sözleşmenin ikinci maddesi hükmü ise, **reşit kadının** fuhşa sürüklenmesi, fuhşuna aracılık edilmesi fiillerinin suç olarak tanımlanması yönünde taraf devletlere yükümlülük yüklemektedir:

“Başkalarının cinsel arzularını tatmin etmek için, fuhuş maksadıyla, reşit bir kız veya kadın hile, cebir, tehdit, nüfuzun kötüye kullanılması ve sair zorlayıcı yöntemlerle kullanan, kaçırarak veya baştan çıkaran kimse, suçu oluşturan muhtelif fiiller farklı memleketlerde işlenmiş olsa da cezalandırılacaktır” (m. 2).

Bu Sözleşmeye göre, reşit olan kadın, kendi rızasıyla “başkalarının cinsel arzularını tatmin etmek için” fuhuş icra edebilecektir. Yani reşit kadın, bir menfaat karşılığı olarak, başkalarının cinsel arzularının tatmini amacıyla kendi vücudu üzerinde tasarrufta bulunulmasına yönelik olarak rıza açıklamasında bulunabilecektir ve bu yönde açıkladığı rıza hukuki bakımdan “geçerli” olacaktır.

Söz konusu Sözleşme, reşit kadının **iradesini fesada uğratan yöntemlerle** fuhşa sürüklenmesi, fuhşuna aracılık edilmesi fiillerinin suç olarak tanımlanması hususunda taraf devletlere yükümlülük yüklemektedir. Yani reşit kadının **hile, cebir** veya **tehditle**, üzerindeki **nüfuz kötüye kullanılarak** ve **sair zorlayıcı yöntemlerle** fuhşa sürüklenmesi, fuhşuna aracılık edilmesi fiilleri suç olarak tanımlanabilecektir.

Söz konusu Sözleşmeye ek olarak imzalanan aynı (4.5.1910) tarihli “**Nihai Protokol**”le, Sözleşmenin 1 ve 2. maddelerinde yer alan “küçük” ve “reşit” ibarelerinden neyin anlaşılması gerektiği hususuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır:

“1 ve 2. maddelerde bahsedilen suçların cezalandırılması hakkında, “küçük bir kız veya kadın, reşit bir kız veya kadın” tabirleri, “20 yaşının üstünde veya altındaki kız veya kadın” şeklinde anlamlandırılması gerekir. Ancak iç hukuk düzenlemeleriyle, her millete tâbi kadın ve kız olacak şekilde aynı koşullarda koruma sağlayacak şekilde daha yüksek bir yaş haddi belirlenebilir.” (bent B).

Buna göre, henüz **20 yaşını doldurmamış kadın**, “küçük”; **20 yaşını tamamlamış kadın** ise, “reşit” kabul edilecektir.

Söz konusu Nihai Protokolde, 4.5.1910 tarihli Sözleşmenin taraf devletlere suç ihdası ve cezalandırma yükümlülüğü getiren 1 ve 2. maddeleri düzenlemelerinin asgari şartları oluşturduğu belirtilmiştir:

“1 ve 2. maddenin hükümleri, asgari düzeydeki bir duyarlılıkla değerlendirilmesi gerekir ki âkit Devletler, hiç kuşkusuz ki, hile veya cebir olmaksızın reşit kişileri kullanma gibi diğer benzer suçları da cezalandırma konusunda serbesttirler.” (bent A).

Buna göre, taraf devletler, reşit kadının rızasıyla da olsa fuhuş amacıyla bir ülkeden başka bir ülkeye götürülmesi, fuhşuna aracılık edilmesi fiillerini cezalandırma yönünde düzenleme yapabileceklerdir. Ancak, söz konusu Sözleşme ve Nihai Protokolde bu fiillerin suç olarak tanımlanması ve faillerinin cezalandırılması hususunda devletlere bir yükümlülük yüklenmemiştir.

3) Milletlerarası alanda üçüncü sözleşme ise, **30.9.1921** tarihinde Cenevre’de imzaya açılan **“Kadın ve Çocuk Ticaretinin Kaldırılmasına Dair Milletlerarası Sözleşme”**dir.

Söz konusu Sözleşme ile fuhşa sürüklenen kişinin münhasıran kadın olmasından vazgeçilmiş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, **çocukların** fuhşa karşı koruma altına alınması yönünde taraf devletlere yükümlülük yüklenmiştir:

“Yüksek Âkit Taraflar, cinsiyet fark etmeksizin çocuk ticaretiyle meşgul olan şahısların ve 4 Mayıs 1910 tarihli Antlaşmanın 1. maddesi altında hüküm altına alınan suçları işleyen şahısların araştırılması ve cezalandırılması için bütün tedbirleri almayı kabul etmişlerdir.” (m. 2).

Keza, söz konusu Sözleşme ile 4.5.1910 tarihli Sözleşmenin 1. ve 2. maddeleri kapsamına giren fiillere **teşebbüsün** ve hatta **hazırlık hareketlerinin** de suç olarak tanımlanması ve ceza yaptırımına bağlanması yönünde taraf devletlere yükümlülük yüklenmiştir:

“Yüksek Âkit Taraflar, suça teşebbüsün ve yasal sınırlar içinde, 4 Mayıs 1910 tarihli Antlaşmanın 1 ve 2. maddelerinde belirtilen suçların işlenmesine yönelik hazırlık hareketlerinin cezalandırılmasını güvence altına almak için gerekli adımları almayı kabul etmişlerdir.” (m. 3).

Bu suretle, kadın veya cinsiyet farkı gözetmeksizin çocuk olsun, kişilerin fuhuş amacıyla bir yerden başka bir yere götürülmesi götürülmesine teşebbüs edilmesi götürülmesine yönelik hazırlık hareketlerinde bulunulması, kişilerin fuhşa yönlendirilmesi, kişilerin fuhşuna aracılık edilmesi fiillerinin suç olarak tanımlanması konusunda taraf devletlere yükümlülük yüklenmiştir.

Keza, söz konusu Sözleşme, reşit kadınların fuhşu bir geçim kaynağı, bir para kazanma aracı olarak icra edebilmeleri yönünde açıkladıkları rızanın “geçerli” olabilmesi için yaş sınırını **21** olarak belirlemiştir (m. 5). Buna göre, **21 yaşını**

tamamlamış olan reşit **kadın**, bir menfaat karşılığı olarak, başkalarının cinsel arzularının tatmini amacıyla kendi vücudu üzerinde tasarrufta bulunulmasına yönelik olarak rıza açıklamasında bulunabilecektir ve bu yönde açıkladığı rıza hukuki bakımdan “geçerli” olacaktır.

Türkiye, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan **Lozan Sulh Muahedenamesi** (m. 100, bent 5) ile bu üç Sözleşmeye iltihak etmeyi taahhüt etmiştir. “*Lozan Sulh Muahedenamesinin Kabulüne Dair Kanunlar*”dan 10 Muharrem 1342/23 Ağustos 1339 tarihli ve 340 sayılı Kanunla, söz konusu Barış Anlaşması ve bu Anlaşmayla iltihak taahhüdünde bulunulan sözleşmeler onanmış bulunmaktadır⁷². Bu iltihak ve onay yöntemi nedeniyledir ki, **söz konusu üç Sözleşmenin**, Türkiye tarafı olmakla birlikte, **resmi Türkçe metni bulunmamaktadır**.

4) Milletlerarası alanda dördüncü sözleşme, **11.10.1933** tarihinde Cenevre’de imzalanan “**Reşit Kadın Ticaretinin Men’i İçin Beynelmilel Mukavelename**”dir.

Söz konusu Sözleşme ile, **kendi rızasıyla da olsa**, reşit kadının fuhuş amacıyla başka bir ülkeye götürülmesi fiillerinin suç olarak tanımlanması yönünde taraf devletlere yükümlülük yüklenmiştir:

*“Bir başkasının ihtiraslarını tatmin etmek üzere **reşit** bir kadın veya bir kızı, **kendi rızasıyla da olsa bile**, başka bir memlekette icrayı fuhuş maksadile kullanan, sürükliyen veya baştan çıkaran kimse, suç unsurlarını teşkil eden fiillerin her biri ayrı ayrı memleketlerde yapılmış bulunsan bile, cezalandırılacaktır.”* (m. 1, f. 1).

Söz konusu Sözleşmeye göre, **reşit kadının**, 21 yaşını tamamlamış olsa bile, bir menfaat karşılığı olarak, başkalarının cinsel arzularının tatmini amacıyla kendi vücudu üzerinde tasarrufta bulunulmak üzere yabancı bir memlekete getirilmesine yönelik olarak **açıkladığı rıza**, konu itibarıyla hukuken **geçerli olmayacaktır**.

Ancak belirtmek gerekir ki, 30.9.1921 tarihli Sözleşmeyi tamamlayıcı mahiyet taşıyan söz konusu Sözleşme, ülke içinde reşit bir kadının kendi rızasıyla fuhuş icrasına yönelik ilave bir kısıtlama getirmemektedir.

30.9.1921 tarihli Sözleşmede olduğu gibi, bu Sözleşmede de, reşit kadının fuhuş amacıyla bir başka ülkeye götürülmesi fiillerine **teşebbüsün** ve hatta **hazırlık hareketlerinin** de suç olarak tanımlanması ve ceza yaptırımına bağlanması yönünde taraf devletlere yükümlülük yüklenmiştir:

“Teşebbüs ve kanunî hududlar içinde kalmak şartile ihzarî fiiller dahi cezalandırılır.” (m. 1, f. 2).

⁷² Türkiye ayrıca, 27.4.1932 tarihli ve 12717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 18.5.1904 ve 4.5.1910 Sözleşmelerini tamamlayıcı mahiyetteki 30.9.1921 tarihli Sözleşmeye iltihak kararı almış, bu kararı Milletler Cemiyeti Umumi Kâtibliğine (Genel Sekreterliğine) bildirmiş ve 15.4.1937 tarihi itibarıyla söz konusu Sözleşmelere taraf olmuştur.

Söz konusu Sözleşme, taraf devletler arasında fuhuşla mücadele konusunda daha etkin bir işbirliğini ve daha kapsamlı bir bilgi alışverişini amirdir (m. 3).

Türkiye, bu Sözleşmeyi 15.4.1935 tarihli ve 2693 sayılı Kanunla onamıştır⁷³.

5) Milletlerarası alanda beşinci sözleşme, **21.3.1950** tarihli “**İnsan Ticaretinin ve Başkalarının Fuhşunu Sömürmenin Önlenmesine Dair Sözleşme**”dir. Söz konusu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2.12.1949 tarihinde kabul edilerek üye devletlerin imza ve onayına sunulmuştur.

Bu Sözleşmenin başlangıcında, fuhşun insan kişiliğinin haysiyet ve değeriyle bağdaşmadığı, toplum, aile ve kişinin selametiyle bağdaşmadığı ve bütün bunları tehlikeye soktuğu ifade edilmiştir. Keza, Sözleşmede; *rızası olsa bile, bir kimseyi fuhuş icrası maksadıyla kullanan, fuhşa sürükleyen, diğer bir kişinin fuhşunu rızasıyla de olsa sömüren, genelevi işleten, işlettiren, işletilmesine tavassut eden, bu tür faaliyetleri finanse eden kimselerin cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu suçlara teşebbüs ve hatta, hazırlık hareketlerinin de cezalandırılması* öngörülmüştür. Sözleşme ayrıca taraf devletlere, *fuhşu bir ticari kazanç aracı olarak yani meslek olarak icrasını ve bunun şartlarını düzenleyen yürürlükteki mevzuatının ilga edilmesini* de bir yükümlülük olarak tahmil etmektedir⁷⁴.

Fuhuş alanında en kapsamlı hükümler içeren söz konusu Sözleşme ile, **kendi rızasıyla da olsa** (“*even with the consent of that person*”), reşit olsun veya olmasın, yaşı ne olursa olsun, bir kişinin fuhşa yönlendirilmesi, fuhşuna aracılık edilmesi ve fuhşunun istismar edilmesi fiillerinin suç olarak tanımlanması yönünde taraf devletlere yükümlülük yüklenmiştir (m. 1).

Keza, söz konusu Sözleşme, taraf devletlere “genelev”, “birleşme evi” (“brothel”) işletilmesi, finanse edilmesi ve “genelev”, “birleşme evi” olarak işletilmek üzere yer temini fiillerinin de suç olarak tanımlanması yönünde yükümlülük yüklemektedir (m. 2).

Dikkat edilmelidir ki, **söz konusu Sözleşme, yaşı ne olursa olsun, bir kadının, rızaya dayalı da olsa, fuhuş icrasının önüne geçmek için taraf Devletlere yükümlülük yüklemektedir.** Başka bir ifadeyle, **söz konusu Sözleşme, reşit olsa bile, kadının fuhuş icrası yönündeki iradesine hukuki değer atfetmemektedir.**

Türkiye, bu Sözleşmeyi henüz imzalamamıştır.

III. Türkiye’nin taraf olduğu çeşitli anlaşmalarda, dolayısıyla da olsa fuhuşla ilgili olarak çeşitli hükümlere yer verilmiştir.

Bu çerçevede ilk sözleşme, Birleşmiş Milletler “**Kadınlara Karşı Her Türli Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme**”dir. Türkiye, söz konusu Sözleşmeyi onaylamıştır⁷⁵. Sözleşmeye göre,

⁷³ Onay Kanunu ve Sözleşme metni için bkz. RG: 22 Nisan 1935/2984.

⁷⁴ Bu hususta bkz. TCK’nın “Fuhuş” suçunu düzenleyen 227. maddesinin gerekçesinde yer alan açıklamalar.

⁷⁵ Sözleşme metni için bkz. RG: 14 Ekim 1985/18898.

“*Taraf Devletler, kadın ticareti ve fahişeliğin istismarının her şekliyle önlenmesi için yasama dâhil gerekli bütün önlemleri alacaklardır.*” (m. 6).

İkinci Sözleşme, “**Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol**”dür⁷⁶.

Söz konusu Protokolün amaçları arasında,

“*a) Kadın ve çocuklara özel önem verilerek, insan ticaretini önlemek ve mücadele etmek,*

(b) Bu tür ticaretin mağdurlarını, onların insan haklarına bütünüyle saygı göstererek korumak ve onlara yardım etmek,”

zıkredilmiştir (m. 2).

Protokole göre;

“*(a) ‘İnsan ticareti’, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi, asgari olarak, başkalarının fuhuşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını içerecektir.*

(b) İnsan ticaretinin (a) bendinde belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle yapılmış olması halinde, mağdurun bu istismara razı olup olmaması durumu değiştirmeyecektir.” (m. 3).

Üçüncü Sözleşme, Birleşmiş Milletler “**Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol**”dür⁷⁷. Söz konusu Protokole göre,

“*Taraf Devletler çocuk satışını, çocuk fahişeliğini ve çocuk pornografisini bu Protokol uyarınca yasaklayacaklardır.*” (m. 1).

“*Çocuk fahişeliği, bir çocuğun ücret veya başka herhangi bir şey karşılığında cinsel faaliyetlerde kullanılması demektir.*” (m. 2, bent b).

⁷⁶ Protokol metni için bkz. RG: 18 Mart 2003/ 25052; Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, **Türk Ceza Hukuku Mevzuatı**, Cilt 3 (Milletlerarası Sözleşmeler), Ankara, Nisan 2017, sh. 365 vd.

⁷⁷ Protokol metni için bkz. RG: 28 Haziran 2002/ 24799; Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, **Türk Ceza Hukuku Mevzuatı**, Cilt 3 (Milletlerarası Sözleşmeler), Ankara, Nisan 2017, sh. 63 vd.

Söz konusu Protokolde **fuhuş**, çocuğun ve genel olarak **kişinin “ücret veya başka herhangi bir şey karşılığında cinsel faaliyetlerde kullanılması”** şeklinde tanımlanmıştır.

Protokol, taraf devletlere,

*“Çocuğun, 2. maddede tanımlandığı üzere, çocuk fahişeliği amacıyla **teklifi, elde edilmesi, tedariki veya temini**”*

filinin suç olarak tanımlanması yönünde yükümlülük yüklemiştir. (m. 3, f. 1, bent b).

Dördüncü Sözleşme, **“Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”**⁷⁸.

Söz konusu Sözleşmeye göre taraf devletler,

“a- çocukların cinsel sömürüsü ve istismarını engellemek ve bunlarla mücadele etme(yi),

b- cinsel sömürü ve istismara maruz çocuk mağdurların haklarını koruma(yı),

c- çocukların cinsel sömürü ve istismarına karşı ulusal ve uluslararası işbirliği geliştirme”yi,

amaç edinmişlerdir (m. 1, f. 1). Bu amaç çerçevesinde söz konusu Sözleşmede taraf devletlere çeşitli yükümlülükler yüklenmektedir.

IV. Türkiye, 21.3.1950 tarihli “İnsan Ticaretinin ve Başkalarının Fuhşunu Sömürmenin Önlenmesine Dair (Birleşmiş Milletler) **Sözleşme”**sini henüz imzalamamış olmakla birlikte, 5237 sayılı yeni TCK’nın “Fuhuş” suçuna ilişkin tanımında (m. 227) bu Sözleşme hükümleri esas alınmıştır⁷⁹. Bu itibarla, **yeni Türk Ceza Kanunu, reşit olsa bile, hatta yaşı ne olursa olsun, kişinin fuhuş icrası yönündeki iradesine hukuki değer atfetmemektedir.**

Ancak, fuhuşla ilgili olarak yukarıda sözünü ettiğimiz, Birleşmiş Milletler teşkilatından önceki anlaşmaları esas alan mülga 765 s. TCK’nın düzenlemeleri, **21 yaşını tamamlamış olan bir kadının rızaya dayalı olarak fuhuş icrasını ceza hukukunun ilgi alanı dışında değerlendirmişti** (m. 436)⁸⁰. Başka bir ifadeyle,

⁷⁸ Sözleşme metni için bkz. RG: 10 Eylül 2011/ 28050; Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, **Türk Ceza Hukuku Mevzuatı**, Cilt 3 (Milletlerarası Sözleşmeler), Ankara, Nisan 2017, sh. 85 vd.

⁷⁹ 4.5.1910 ve 30.9.1921 Sözleşmeleri Türkiye ve pek çok devlet tarafından onaylanmıştır. Birleşik Krallık (İngiltere) ve ABD bu Sözleşmeleri imzalayan ve onaylayan devletler arasında bulunmamaktadır. Keza, 21.3.1950 tarihli Sözleşme, pek çok ülke tarafından onaylanmış olmakla birlikte, Türkiye, Birleşik Krallık (İngiltere), ABD, Almanya ve Hollanda tarafından 2017.01.06 tarihi itibarıyla imzalanmamıştır.

Buna rağmen, örneğin İngiltere fuhuş aleliltak yasaklamış iken, Hollanda’da Türkiye’de olduğu gibi 21 yaşını doldurmuş olan kadınların devletin gözetim ve denetimi altında fuhuş icrasına izin verilmektedir.

Bu nedenledir ki, ülkeler arasında kürtaj veya uyuşturucu madde kullanımı turizmi gibi **fuhuş turizmi** de gelişmiştir.

⁸⁰ Bu nedenledir ki, mülga 765 s. TCK uygulamasında, 21 yaşını tamamlamış olan kadının rızaya dayalı olarak fuhuş icrası, kamu sağlığı yönünden Devletin gözetim ve denetimi dışında da

765 s mülga TCK, **21 yaşını tamamlamış olan reşit bir kadının fuhuş icrası yönündeki iradesine hukuki “değer” atfetmekteydi.** Keza yeni Türk Ceza Kanununa ilişkin “*Dönmezer Tasarısı*” olarak bilinen Hükümet Tasarısı da, **18 yaşını tamamlamış olan bir kadının rızaya dayılı olarak fuhuş icrasını ceza hukukunun ilgi alanı dışında değerlendirmekte idi** (m. 323, f. 1)⁸¹.

Mülga 765 s. TCK’nın fuhuş suçuna ilişkin düzenlemelerinde, **4.5.1910 ve 30.9.1921** tarihli Sözleşmeler hükümleri esas alınmıştı⁸².

Bu anlayışın bir yansıması olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı **Umumi Hıfzıssıhha Kanununun** “*Umumi kadınlar hakkında ahkam*” başlıklı Üçüncü Ba-bında yer verilen hükümlere göre, Türkiye’de Devletin gözetim ve denetimi altın-da fuhuş icrasına ve “**umumi ev**” açılmasına **izin** verilebilecektir (m. 128). Söz konusu Kanuna göre “**umumi kadınlar**” (m. 128), “**fuhuş sanat ve maişet vasi-tası ittihaz eden kadınlar**” olarak tavsif edilmiştir (m. 129). Söz konusu Kanun hükümlerine göre, genel sağlığın korunması amacıyla, yani bulaşıcı hastalık ya-yılması riskinin bulunması halinde, bu “sanat”ı icra eden kadınlar, “sanatlarının icrasına icap ederse **kuvvei cebriye** istimali ile **mümanaat** olunur. Bunlar lüzum görülürse bir müessesede **tecrit ve tedavi edilir.**” (m. 129), yani gerektiğinde **zor kullanılarak**, fuhuş icrasından men edilir, **karantina** altına alınır ve **tedavi** edilir. Bunun dışında söz konusu Kanunda bir kadının hangi koşullarla bu “sanat”ı icra edebileceği konusunda herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Söz konusu Kanun mesnet ittihaz edilerek, Bakanlar Kurulu’nun 30.3.1961 tarihli ve 5/984 sayılı kararıyla⁸³ kabul edilen ve bilahare 31.1.1973 tarih ve 7/5786 sayılı kararıyla⁸⁴ değiştirilen “**Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü**” çıkarılmıştır. Söz konusu Tüzük hükümlerine göre, bir “**sanat**” olarak nite-len fuhuş, ancak **kadınlar tarafından** icra edilebilir⁸⁵.

olsa, suç oluşturmamakta idi: Yargıtay 5. CD, 25.1.1993, 4147/165 (Savaş, Vural/Mollamah-mutoğlu, Sadık: Türk Ceza Kanunu Yorumu, cilt III, 3. bası, Ankara 1999, sh. 4175); Yargı-tay 5. CD, 30.12.1987, 1056/8125 (Savaş/Mollamahmutoğlu, III, 3. bası, sh. 4176); Yargıtay 5. CD, 21.1.1986, 3740/85 (Savaş/Mollamahmutoğlu, III, 3. bası, sh. 4177); Yargıtay 5. CD, 9.10.1985, 2760/3739 (Savaş/Mollamahmutoğlu, III, 3. bası, sh. 4177).

⁸¹ Türk Ceza Kanunu (Dönmezer) Öntasarılarında da, **18 yaşını** bitirmiş kişinin fuhuş icrası yönünde açıklayacağı rızaya “hukuken geçerlilik” tanıma yönünde düzenlemeler yapılmıştı (1987 Öntasarısı, m. 281 ve gerekçesi; 1989 Öntasarısı, m. 317 ve gerekçesi; 1997 Öntasarısı, m. 322 ve gerekçesi). Ancak yaş sınırının 21’den 18’e çekilmesinin dayanağı ile ilgili olarak gerekçelerde herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

⁸² Fuhuş icrası yönünde açıklanan rızaya “hukuken geçerlilik” tanınması bakımından yaş sınırının belirlenmesinde 30.9.1921 tarihli Sözleşme hükümleri esas alınmıştı.

Keza, 4.5.1910 tarihli Sözleşme hükümleri dikkate alınarak, mülga 765 sayılı TCK’nın 11.6.1936 tarihli ve 3038 sayılı Kanunla değiştirilen 435. maddesinde “*kız ve kadın*” (f. 5), 436. maddesinde ise “*bakir veya kadın*” ibareleri kullanılmıştı.

⁸³ RG: 19 Nisan 1961/10786.

⁸⁴ RG: 18 Şubat 1973/14452.

⁸⁵ ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, Genel Hükümler (13), sh. 175.

Tüzüğün “Genel kadınlar” başlığını taşıyan 15. maddesine göre, «Başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlara “Genel kadın” denilir.».

Nitekim, Yargıtay’a göre; «**Fuhuş**, bir kadının menfaat mukabili veya itiyadî surette vücudunu başkalarının cinsel zevkine teslim etmesi ve bu suretle birçok erkeklerle cinsî münasebette bulunması **san’atı**»dır.⁸⁶

«Fuhuş murakabe etmek, fuhuş sebebiyle bulaşan zührevi hastalıkların yayılmasına ve bu yüzden amme nizamının bozulmasına mani olmak üzere» her ilde bir veya birden fazla “Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu” kurulmaktadır (Tüzük, m. 1, 10). Bir yerde “Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu” teşkili için, o bölgede gerekli sağlık kuruluşlarının yanı sıra, polis ve belediye teşkilatının da bulunması gerekir (Tüzük, m. 2). Söz konusu Tüzük, “Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları”nın teşkili ve işleyişi hususunda vilayet ve kaymakamlık makamlarını yetkili kılmıştır (m. 11).

“Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu” tarafından bir kadının “genel kadın” olarak tesciline karar verilebilmesi için, bu kadının a) fuhuş kendisine “**sanat**” edinmiş olması, b) **21 yaşını bitirmiş olması** ve ayrıca, c) **Türk vatandaşı** olması gerekir (Tüzük, m. 21).

Bu itibarla, söz konusu Tüzük, yabancı kadınların Türkiye’de “fahişelik mesleği”ni icra etmesine izin vermemektedir.

“Genel kadın” olarak çalışmasına, başka bir deyişle, “fahişelik mesleği”nin icrasına izin verilen kadınlar, “Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu” tarafından tescil edilir ve kendilerine fahişe olduklarını tevsik zımında “Hüviyet muayene cüzdanı”⁸⁷ adı altında bir belge verilir (Tüzük, m. 22).

“Fuhuş sanat edinen” kadınların bu “sanat”ı icra edebilecekleri yerler de Tüzükte “Fuhuş yerleri” olarak ifade edilmiştir (m. 19). Buna göre; «Bu Tüzükte

⁸⁶ 5.CD., 30.3.1976, 1002/979 (YKD. Temmuz 1976, sh. 1072).

Yargıtay ilgili Ceza Dairelerince, 765 sayılı TCK döneminde olduğu gibi, 5237 sayılı TCK yürürlüğe girdikten sonra da, fuhuş suçunun bünyesinde devamlılığı barındırdığı ve bu suçla ilgili olarak zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı yönünde içtihatlarla bulunulmuş ise de (bkz. 14.CD, 11.2.2013, E. 2011/22237, K. 2013/1071); Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**, nihayet, TCK’nın 227. maddesinde tanımlanan fuhuş suçunun mahiyeti itibarıyla **kesintisiz (mütemadi)** bir suç olmadığına hükmetmiştir (25.11.2014, E. 2013/14-342, K. 2014/519):

“Fuhuş suçu, TCK’daki düzenleniş biçimi itibarıyla temadi eden, devamlılık gerektiren, diğer bir ifadeyle, ... gerçekleştiğinin kabulü için eylemin ardı ardına yapılmasını zorunlu kalan bir suç değildir.”

Bu içtihadı **doğru** bulduğumuzu hemen ifade etmemiz gerekir.

Madde gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi, **kendi vücudu üzerinde başkalarının cinsel arzularını tatmin amacına yönelik davranışlarda bulunmasına katlanan kişi**, fuhuş suçunun mağduru-
rudur. Yeni TCK’nın düzenlemesi itibarıyla söz konusu suçun mağdurunun kadın olması da şart değildir. Söz konusu CGK Kararında da aynı yönde tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

⁸⁷ “Bu cüzdanda, sahibinin kim olduğunu gösteren bilgilerden başka, sicil kartonundakinin aynı olan bir fotoğrafı ve yılın her ayına mahsus birer sahife üzerine haftada iki defa yapılacak muayenelerin kaydına mahsus haneleri gösteren bir kısım bulunur. Bu cüzdanlar her yıl değiştirilir.” (Tüzük, m. 22).

geçen (Fuhuş yerleri) tabiri; genel ev, birleşme yerleri ve tek başına fuhuş yapılan evleri kapsar.»⁸⁸

5237 sayılı yeni TCK'nın "Fuhuş" suçuna ilişkin 227. maddesi düzenlemeleri karşısında, 1593 sayılı **Umumi Hıfzıssıhha Kanununun fuhuş icrasına izin veren hükümleri** ile bu hükümlere istinaden çıkarılan söz konusu **Tüzük**, zımnen **ilga edilmiştir**. Ancak belirtmek gerekir ki, yeni TCK'nın düzenlemelerine rağmen, **namuslu bir hayatla ve ahlâkla telifi kabil olmayan⁸⁹ fuhşun⁹⁰** icrasına, sanki yürürlükte imiş gibi söz konusu Kanun ve Tüzük hükümlerine göre Türkiye'de Devletin himayesi, "gözetim ve denetimi" altında devam edilmektedir⁹¹.

Oysa, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Türkiye, fuhşun alelîtlak önlenmesine dair **21.3.1950** tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesini henüz imzalamamış olmakla birlikte, 5237 sayılı TCK'nın "Fuhuş" suçuna ilişkin tanımında (m. 227) bu Sözleşme hükümleri esas alınmıştır.

Yeni TCK'nın düzenlemesine göre, reşit olsa bile, hatta yaşı ne olursa olsun, kişinin fuhuş icrası yönündeki iradesine, konu bakımından hukuki değer atfedilmemiştir, bu iradenin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır⁹².

11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, **ahlaka ve kişilik haklarına aykırı olan sözleşmeler, "kesin olarak hükümsüzdür"** (m. 27)^{93,94}.

⁸⁸ Söz konusu Tüzüğe göre;

«Genel kadınların bir arada oturarak fuhuş yaptıkları veya bu maksat için toplandıkları yerlere "Genel ev" ismi verilir.» (m. 16);

«Fuhuş maksadiyle muhtelif kimselere kısa müddetler için açık bulundurulmuş kapalı yerlere "Birleşme yerleri" denilir.» (m. 17);

«Fuhşu tek başına yapan kadınların ikametgah edinip içinde fuhuş yapmayı itiyat ettikleri yerlere "Tek başına fuhuş yapılan ev" denir.» (m. 18).

⁸⁹ Nitekim bu husus, söz konusu Tüzükte de açıkça ifade edilmiştir (m. 13, bent c; m. 20).

⁹⁰ Normatif bir bilim olan hukukun en önemli özelliği, ahlaki temele oturtulmasıdır. Bu nedenle, bir pozitif hukuk sistemi ve uygulamasının meşruiyet ölçütü, ahlaki temele oturtulmuş olup olmamasıdır. Bu bakımdan üç önemli test örneği bulunmaktadır: Fuhuş, kumar (bahis oyunu) ve faiz.

⁹¹ İstanbul'da üç kişi, FAHİŞELİK "SAN'AT"ını icra etmek için Valiliğe başvurur. Valilik, bu başvuruları reddeder. Bu kişilerin herbiri, bu ret kararlarına karşı İdari Yargıda iptal davası açar. İstanbul İdare Mahkemeleri, bu davaları kabul ederek, Valiliğin ret kararlarını, dava açan kişilerin "genel kadın olarak çalışmasına engel bir halinin bulunmadığı" gerekçesiyle, iptal ederler. İdare Mahkemelerinin söz konusu kararları, Danıştay 10. Dairesi tarafından onanır.

(Danıştay 10. Dairesi, 30.6.2010, E.2009/16486, K.2010/5833;

Danıştay 10. Dairesi, 31.12.2010, E.2010/401, K.2010/11852;

Danıştay 10. Dairesi, 31.12.2010, E.2010/8047, K.2010/1863).

⁹² Yargıtay da yeni TCK yürürlüğe girdikten sonra verdiği kararlarında bu hususa işaret etmiştir: Yargıtay 5.CD, 13.4.2011, E. 2011/290, K. 2011/3055.

⁹³ Yargıtay'ın 14.1.1948 tarihli ve E. 1943/30, K. 1948/2 sayılı **İçtihadı Birleştirme Kararında**, "genelev" olarak kullanılmak üzere kiralanmış gayrimenkule ait sözleşmenin ahlaka aykırılık yönünden muteber olup olmadığı hususu ile ilgili olarak çıkan uyuşmazlık üzerine verdiği kararda, şu tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

Yeni TCK, fuhuş icra eden kişinin münhasıran kadın olmasını da kabul etmemiştir. Yeni TCK'nın düzenlemesine göre, fuhuşun icrası bakımından **kişinin cinsiyetinin bir önemi bulunmamaktadır**. Madde metninde fuhuş icra eden kişi ile ilgili olarak, “**fuhuşa sürüklenen kişi**” ibaresi kullanılmıştır (m. 227, f. 8).

“Borçlar Kanununun 19. maddesi mucibince aktin mevzuu, kanunun gösterdiği hudut dairesinde serbestçe tayin olunabilir. Ancak, bu maddenin ikinci fıkrasında bu serbestliği takyit eden bazı istisnalar vardır. Ezciümle aktin muteber olması için kanun ve ahlaka mugayir olmaması şarttır.

Aksi takdirde Borçlar Kanununun 20. maddesi mucibince o akit batıl olur. Sözü geçen maddelerde kanun ve ahlaka mugayir sayılan akitlerin nelerden ibaret olduğu her türlü şüphe ve tereddüde mahal vermiyecek bir tarzda beyan edilmiş olmayıp sadece kanun ve ahlaka mugayir olan akitlerin batıl olduğu zikrolunmakla iktifa olunmuştur.

Binaenaleyh kanun ve ahlaka mugayir akitlerin tayini; tefsire tabi bir meseledir. Bu hususun tefsir ve tayininde yalnız Borçlar Kanunu hükümlerini nazara almak doğru olmaz. Aynı zamanda memleketin genel sağlığını korumak, inzibat ve intizamı sağlamak ve genel evler üzerindeki murakabe ve nezaret hakkını kullanabilmek için Hükümetçe vazolunan kanunlarla nizamnameleri, emir ve tebliğleri de göz önünde tutmak icap eder.

Mevzuatımıza göre genel evler; ancak Hükümetin izin ve müsaadesiyle açılabilir. Her ne kadar İçişleri Bakanlığının 12 Nisan 1930 günlü tamiminin altıncı bendinde (badema Türkiye'nin hiç bir mıntkasında umumhane açılmasına müsaade ve müsamaha edilmeyeceği) bildirilmiş ise de, sonradan yürürlüğe girmiş olan Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 128 inci maddesine istinaden neşredilen Tüzük ile bu tamimin hükmü kalmamış ve nitekim 24 Mayıs 1931 günlü tamimle ve 12 Haziran 1930 günlü tebliğin Tüzük'e aykırı hükümlerinin kaldırıldığı ayrıca bildirilmiştir.

Bundan başka Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 128, 129, 130, 131 ve 132 inci maddelerinde umumi kadınlar hakkında hususi hükümler konulmuş olduğu gibi zührevi hastalıklarla mücadele nizamnamesinde de bu evlerin nerelerde ve ne gibi şartlar altında açılabilceği ayrıca gösterilmiştir.

*Bu sebeplerden ötürü **Hükümetin izin ve müsaadesi olmaksızın genel ev açmak ve işletmek kanuna ve ahlaka mugayir bulunmuş ise de, Hükümetin izni telahuk edince bu aykırılığın, bahis konusu edilmesine lüzum ve icap kalmaz.***

Ve genel ev olarak kullanılmak üzere kiralanın gayrimenkule müteallik akitlerin kanun ve ahlaka mugayir olduğu yahut ahlaka mugayir bir maksadın istihsalı zımında yapıldığı iddia edilemez.”

⁹⁴ Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 13.12.1976 tarihli ve E. 1976/2884, K. 1976/8294 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, davacı, davalı ile genelev işletmek üzere ortaklık kurarlar. Davacı, ortak olarak işlettikleri genelevin gelirinden kendi payına düşen miktarın tahsili amacıyla dava açar. Davalı diğer ortak ise, “genelev işletmek üzere kurulan ortaklıkların Borçlar Kanununun 19. ve 20. maddelerine aykırı olması nedeni ile geçersiz bulunduğunu, davacının bir şey istemeye hakkı olmadığını” belirterek davanın reddi gerektiğini savunur.

İlk derece mahkemesi, davalının savunmasını dikkate alarak davanın reddine karar vermiştir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise, aşağıdaki gerekçeyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur:

*“Genelev işletmenin ahlaka aykırı olduğundan uyumsuzluk yoktur. Bu müesseseye köleliğin devamını hatırlatan, insanlık haysiyetine yaraşmayan bir müessesedir. Ancak bazı sosyal zorunluluklar nedeni ile ülkemizde hükümetin izni ile genelev işletmesine izin verilmektedir. **Hükümetin izni ile genelev işletmek** duruma ahlakilik kazandırılmaz ise de; ahlakilik tartışmasını pratik olarak önler. Esasen genelev işletmesine hem hükümetçe müsaade edilmek, hem de bu müesseseye ile ilgili bütün işlemlere, sözleşmelere hukuk alanında hiç bir varlık tanımamak mantıkla da bağdaşamaz. ...*

O halde hükümetin izni ile genelev işletilmesinin mümkün bulunmasına ve olayımızda da izni mevcut olmadığına ilişkin bir itiraz ileri sürülmemesine göre genelevin ortak olarak işletilmesine ve ortakların, ortaklıktan doğan haklarını birbirlerinden istemelerine engel yoktur ve bu durumda ahlaki aykırılık iddiası dinlenemez.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, yaşı ne olursa olsun, başkalarının cinsel arzularının tatmini amacıyla fuhuş icra eden kişinin **mağdur** olduğunu kabul etmektedir.

“Kanun koyucu fuhuş yaptırılan kişinin yaşına göre ikili bir ayırım yapmaktadır. Buna göre, maddenin birinci fıkrası yönüyle 18 yaşından küçükler mağdur olarak kabul edilirken, ikinci fıkra yönüyle yetişkinler mağdur olarak kabul edilmiştir.

Mağdur olan kişinin cinsiyetinin bir önemi bulunmadığından, dolayısıyla erkekler dahi kadınlar gibi suçun mağduru olabilecektir.”^{95, 96, 97}.

⁹⁵ Yargıtay CGK, 30.6.2015, E. 2015/9-49, K. 2015/255; Yargıtay CGK, 25.11.2014, E. 2013/14-342, K. 2014/519. Ayrıca bkz. Yargıtay CGK, 1.10.2013, E. 2012/5-1338, K. 2013/403.

⁹⁶ Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 6.3.2017 tarihli ve E. 2015/24345, K. 2017/2377 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, kolluk görevlisi X, “müşteri” izlenimi oluşturarak, “genelev” olarak işletilen yere girer. Fuhuş icrasında bulunan bayan T, X’in kabul edildiği odada soyunmaya başlar. Bu sırada X, kendisinin polis olduğunu söyler. Başlatılan soruşturmada tanık olarak dinlenen T, kendisinin fuhuş icrası için A tarafından istihdam edildiğini söyler.

Daire, bu olayda, A bakımından TCK m. 227, f. 2’de tanımlanan fuhuş suçunun oluştuğunu kabul etmiştir.

Dikkat edilmelidir ki, söz konusu olayda T, reşit bir kadındır. A bakımından fuhuş suçunun oluşabilmesi için T’nin mutlaka cebir veya tehditle fuhuş sürüklenmesi gerekmemektedir.

⁹⁷ Yargıtay’a göre, bir kişinin fuhuşuna aracılık edilerek birden fazla kişinin cinsel arzularının tatmin edilmesinin sağlanması halinde, “Fuhuş” suçundan (TCK, m. 227) dolayı verilecek olan cezanın zincirleme suç hükümlerine göre artırılması gerekir (Yargıtay CGK, 11.2.2014, E. 2013/14-310, K. 2014/60; Yargıtay 18. CD, 11.5.2016, E. 2015/23974, K. 2016/10104; Yargıtay 14. CD, 25.11.2013, E. 2013/9170, K. 2013/12053). Bu yöndeki içtihatları doğru bulmaktayız. Bu durumda suçun mağduru bir kişidir. Keza belirtelim ki, söz konusu suç, temadi eden (kesintisiz) suç mahiyeti taşımamaktadır (Yargıtay CGK, 25.11.2014, E. 2013/14-342, K. 2014/519).

Yargıtay’a göre, birden fazla kişinin fuhuşuna aracılık edilmesi halinde ise, zincirleme suç hükümlerinin değil, gerçek içtima hükümlerinin uygulanması gerekir. Yani bu durumda mağdur sayısının fuhuş suçunun işlendiğinin kabulü ve buna göre cezaya hükmedilmesi gerekir (Yargıtay CGK, 28.5.2013, E. 2012/14-1392, K. 2013/274; Yargıtay 14. CD, 20.2.2014, E. 2012/4297, K. 2014/2070; Yargıtay 14. CD, 25.11.2013, E. 2013/9170, K. 2013/12053; Yargıtay 5. CD, 5.7.2010, E. 2009/420, K. 2010/5922). Bu yöndeki içtihatları doğru bulmaktayız.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bir kararında (25.11.2014, E. 2013/14-342, K. 2014/519) farklı anlaşılmaya sebebiyet verecek bir ifade kullanılmış ise de, karara konu teşkil eden olayda birden fazla kişinin fuhuşuna aynı ve farklı zamanlarda aracılık edilmiştir. Birden fazla kişinin fuhuşuna farklı zamanlarda aracılık edilmesi durumunda, gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır. Hatta, her bir mağdur bakımından zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Ancak, birden fazla kişinin fuhuşuna aynı zamanda aracılık edilmiş ise, aynı neviden fikri içtima hükümlerini uygulamak gerekecektir. Bu nedenle, Ceza Genel Kurulu’nun söz konusu kararını da ilişkin olduğu olay bakımından doğru bulmaktayız.

Mülga 765 s. TCK uygulamasında da, fuhuşuna aracılık edilen kadın sayısının fuhuş suçunun oluştuğu kabul edilmekteydi: Yargıtay 5. CD, 17.3.1993, 860/1218 (Savaş/Mollamahmutoğlu, III, 3. bası, sh. 4175); Yargıtay 5. CD, 17.3.1970, 735/845 (Savaş/Mollamahmutoğlu, III, 3. bası, sh. 4180).

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, fuhuş icrası amacıyla birden fazla kadının başka bir ülkeden Türkiye’ye getirilmesi halinde, bunların aynı veya farklı zamanda getirilmiş olması arasında bir ayırım yapmaksızın, “İnsan ticareti” (TCK, m. 80) suçundan dolayı kurulan mahkumiyetle il-

Ancak belirtmek gerekir ki, Yargıtay'ın bu kabulü, gerekli izin alınmaksızın, Devletin gözetim ve denetimi dışında fuhuş icra eden kişilerle sınırlıdır. Zira, 5237 sayılı TCK'nın 227. maddesindeki "Fuhuş" suçuna ilişkin düzenlemeler karşısında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun fuhuş icrasına izin veren hükümleri ile bu hükümlere istinaden çıkarılan söz konusu Tüzük ilga olmuş olmasına rağmen, halen Türkiye'de geçerli genel kabul itibarıyla, malum Tüzük hükümlerine (m. 20) göre "vesika" sahibi olan kişi, "hukuka uygun" bir "san'at" icra etmektedir^{98, 99}.

gili olarak, aynı neviden fikri içtima (TCK, m. 43, f. 2) hükümlerinin uygulanması yönünde içtihatla bulunmuştur (6.12.2016 tarihli ve E. 2016/15853, K. 2016/18706 sayılı Karar).

Bu içtihadı doğru bulmamaktayız. Eğer birden fazla kadın fuhuş amacıyla yurt dışından Türkiye'ye birlikte getirilmiş ise, olayda aynı neviden fikri içtima hükümlerini uygulamak gerekir. Buna karşılık, farklı kadınlar farklı zamanlarda Türkiye'ye getirilmiş ise, zincirleme suç hükümlerini uygulamak mümkün olmayacaktır. Bu durumda "İnsan ticareti" suçundan dolayı gerçek içtima hükümlerine göre cezaya hükmetmek gerekecektir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 13.2.2017 tarihli ve E. 2015/24030, K. 2017/1481 sayılı Kararı-na konu teşkil eden olayda henüz çocuk olan M, fuhuş yapmak için bir yere götürülmeye zorlanır. Bu amaçla failler M'ye cebir ve şiddetle baskı uygularlar. Bu baskılar karşısında M başka bir ile götürülmeye ve burada fuhuş icrasına mecbur bırakılır.

Daire bu olayda, hem TCK, m. 80'de tanımlanan "İnsan ticareti" suçunun, hem de TCK, m. 227, f. 1 ve 4'de tanımlanan nitelikli "Fuhuş" suçunun işlendiği, fuhuş suçu bakımından zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği ve her iki suçtan dolayı gerçek içtima hükümlerine göre cezaya hükmedilmesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

Bu çözüm şeklini doğru bulmaktayız.

Yargıtay'a göre, "İnsan ticareti" suçunun fuhuş amacıyla icra edilmesinden sonra, bu suçun mağdurunun ayrıca fuhuşa aracılık edilmesi halinde, her iki suçtan dolayı gerçek içtima hükümlerine göre cezaya hükmetmek gerekecektir. (Yargıtay 18. CD, 4.11.2015, E. 2015/24178, K. 2015/10157). Bu yöndeki içtihatları doğru bulmaktayız.

⁹⁸ **Anayasa Mahkemesinin** bir bireysel başvuru üzerine verdiği **18.10.2017** tarihli ve 2014/19152 numaralı karar (RG: 21 Aralık 2017/30277), hukuk camiamızın konuya vakıf olmadığının açık göstergesidir.

Yüksek Mahkemenin diğer bir bireysel başvuru üzerine verdiği **4.7.2018** tarihli ve 2014/18275 numaralı karar (RG: 19 Eylül 2018/30540), sonuç itibarıyla doğru olmakla birlikte, gerekçesi itibarıyla yetersizdir ve hatta, yer yer tutarsızlıklar içermektedir.

Yüksek Mahkemeye göre,

"yetişkin bireylerin rızasıyla *fahişelik* yapmasının insan hakları açısından korunabilen bir değere sahip olup olmadığı tartışmalıdır" (pn. 49).

"... rıza *insan olma* olgusunun varlığıyla ilgili olup bireyin rızasıyla kendi onuruna mugayir davranışta bulunması *insanlık* bakımından kabul edilemez niteliktedir" (pn. 49).

"Kişiyi *fahişelik* yapmaya iten nedenlerin varlığından bağımsız olarak rızayı tartışmak anlamsız kalacaktır" (pn. 50).

"... *fahişelik yapma* eyleminde *geçerli* rızanın varlığından kolaylıkla söz edilemez ... Rızaya dayalı olup olmamasına bakılmaksızın fuhuş, insan onuru ve değeri ile bağdaşmamaktadır" (pn. 51).

"Rızasıyla fuhuşu ifa eden yetişkin bireylerin bir taraftan bu rızalarının geçerliliği tartışılmalıyken, diğer yandan bu şekilde yapılan eylemlerin bir eğitim veya yetenek unsuruna bağlanması suretiyle *meslek* sayılması insan haysiyetiyle bağdaşmaz niteliktedir" (pn. 56).

"Ayrıca Türkiye'de olduğu gibi bazı ülkelerde fuhuşun yasaklanmayıp düzenlenmesi yoluyla kontrol altına alınmasının zorunlu sonucu olarak ortaya çıkan fuhuştan elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Ş2. Ceza Hukukunun Fonksiyonu

Genel olarak ceza hukuku, esasen haksızlık teşkil eden davranışlardan hangilerinin suç olarak nitelendirilmesi gerektiğini ve bu davranışlar karşılığında ceza hukuku yaptırımını olarak ne tür yaptırımların uygulanabileceğini belirleyen bir hukuk disiplini¹⁰⁰. Kısacası, ceza hukuku, ceza ve güvenlik tedbirlerinin önleyici etkisiyle, hukuki değerleri korumaya yönelik bir fonksiyon icra etmektedir¹⁰¹.

Buna göre ceza hukuku, esasen haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin suç olarak tanımlanması gerektiğine ve bu davranışların hangi koşullar altında işlenmesi halinde suç oluşturacağına dair esasları belirler¹⁰². Keza, bu disiplin, suç olarak tanımlanan davranışlar dolayısıyla bunları gerçekleştiren kişiler hakkında ne tür yaptırımların uygulanması gerektiğini, bu yaptırımların infazına dair esasları belirlemektedir.

Bütün bu esas ve prensipler, izlenen *suç ve ceza siyaseti* ile belirlenmektedir.

Barış esasına dayalı *değerler toplumunun*¹⁰³ varlığını devam ettirebilmesi, toplumu oluşturan insanların davranış normlarının icaplarına göre hareket etmele-

veya profesyonel olarak fuhuş yapan kişilerin sosyal güvenlik kayıtlarının bulunması fuhşun mesleki faaliyet olarak sınıflandırılması için yeterli kıstas kabul edilemez” (pn. 56).

Oyçokluğuyla alınan bu karara muhalif kalan Üyenin karşıoy yazısında, “çoğunlukça benimsenen **“rızaıyla yapılan fuhşun meslek sayılmasının insan haysiyetiyle bağdaşmayacağı”** ve fuhşun özel hayata saygı kapsamında korunması gereken bir unsur olmadığı **düşüncesine katılmaya imkân yoktur”** açıklamasına yer verilmiştir.

⁹⁹ Bir Yahudi fıkrasına göre, kasabanın “genelevi”nin Yahudi olan patronu ölür. Bunun üzerine yedi gün yas tutulur. Bu süre zarfında “genelev” “müşteri” kabul etmez ve ölenin arkasından Yahudi inancına göre yapılan dini merasimler de “genelev”in giriş salonunda icra edilir. Bu merasim, kasaba Hahambaşılığının ve bütün meslek erbabının katılımıyla gerçekleştirilir.

Yas bittikten bir süre sonra, bir avukat Hahambaşına gelerek bir mektup verir. Mektup, ölen patronun vasiyetnamesidir ve içeriğine göre patron bütün malvarlığını, gelirleriyle birlikte “genelev”i Hahambaşılığa miras olarak bırakır.

Hahambaşı bu mirasın kabulünün “zor” bir iş olduğunu düşünür ve konuyu görüşmek üzere, “Hahamlar Kurulu”nu toplantıya çağırır. Toplantıda uzun süren tartışmalar sonucunda aşağıdaki karar verilir:

“Aldıkları hizmet karşılığında Cemaat mensupları tarafından genelev patronuna kazandırılan paranın tekrar Cemaate geri dönmesinde dinen bir mahzur bulunmamaktadır.”

¹⁰⁰ Suç olarak tanımlanan haksızlıklar ile sadece özel hukuk yaptırımını gerekli kılan haksızlıklar arasında bir nitelik farkı bulunmamaktadır. Ancak “cezalandırmaya layık” ve “cezalandırmaya muhtaç” haksızlıklar, suç olarak tanımlanmaktadır (Bkz. ÜNVER, Yener: *Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer*, Ankara, 2003, sh. 430).

¹⁰¹ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 107. Yazar, çalışmasının çeşitli yerlerinde ceza hukukunun amacının hukuki değerlerin korunması olduğunu vurgulamaktadır (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 428, 436 vd., 607).

¹⁰² Ceza hukukunun **ultima ratio** karakteri gereğince, haksızlık oluşturan fiillerin, ancak özel hukuk gibi diğer hukuk disiplinlerinde öngörülen yaptırımlarının yetersiz kalması halinde, suç olarak tanımlanması yoluna gidilebilir (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 446, 457).

¹⁰³ “Wertegesellschaft”

rine bağlıdır. Toplumsal ilişkilerde bir davranış normuna uyulmaması halinde, normu ihlâl eden kişi insanlar nezdindeki saygınlığını yitirmekte, diğer insanlar bu kişi ile olan ilişkilerini azaltmakta ve hatta kesmektedir; kısacası, belli bir davranış normunu ihlâl eden insan, toplumda dışlanmaktadır. Bu olgu, insanların davranış normlarının icaplarına göre hareket etmelerini sağlamaktadır. Davranış normlarını ihlâl etmeyi önlemek amacına hizmet eden ve böylece toplum düzeninin devamına katkıda bulunan bu esasların tümüne *sosyal kontrol* adı verilmektedir¹⁰⁴.

İnsanların kültürel gelişmişlik düzeyiyle yakın alâkası olan bu sosyal kontrol sisteminin hukuk düzeniyle tamamlanması, pekiştirilmesi ve hatta düzeltilmesi gerekir¹⁰⁵. Bütün hukuk disiplinleri gibi, ceza hukuku insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemeye ve böylece toplumsal düzeni sağlamaya katkıda bulunmaktadır. Ceza hukukunda ve diğer bütün hukuk disiplinlerinde hukuk düzeninin geçerliliğinin sağlanması için devlet gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak, ceza hukuku, devlet gücünün diğer hukuk disiplinlerine nazaran daha fazla müdahalesini zorunlu kılmaktadır. **Ceza hukukunun öngördüğü bütün yaptırımlar bir hukuk devletinde ancak devlet tüzelkişiliği tarafından uygulanabilir.**

Ceza hukukunun gerekli kıldığı bu devlet müdahalesi keyfî ve sınırsız olamaz. Devletin bu müdahalesi, yine hukuken öngörülen esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu müdahaleyle, kişilerin hak ve özgürlüklerinin ihlâl edilmemesi gerekir. Kişi hak ve özgürlüklerine devlet eliyle yapılan bu müdahalenin hukukla sınırlandırılması ve devletin bu sınırlamalara sadık kalması, *hukuk devleti* olmanın en önemli ölçütlerini oluşturmaktadır.

¹⁰⁴ İÇEL/DONAY(2), sh. 5.

¹⁰⁵ İÇEL/DONAY(2), sh. 6.

Ş3. Bir Bilim Dalı Olarak Ceza Hukuku

Bir sosyal bilim olan *hukuk*, didaktik ve uygulama bakımından, zaman içerisinde çeşitli disiplinlere ayrılmıştır. Bugün ulaştığı aşamada hukuk bilimi, *kamu hukuku* ve *özel hukuk* olarak bir ayırıma tabi tutulmuştur. **Ceza hukuku**, kamu hukuku altında bir bilim disiplini oluşturmaktadır. Bunun nedeni, suç oluşturan haksızlık dolayısıyla, devletle bu haksızlığı gerçekleştiren kişi arasında bir ilişki tesis edilmesidir.

Ceza hukuku, kendi içinde de birtakım disiplinlere ayrılmaktadır. Bu kapsamda önce **maddi ceza hukuku** ve **ceza muhakemesi hukuku** ayırımına yer verilmiştir.

Maddi ceza hukuku, suçun yapısal unsurlarını, bir suçun yapısında bulunması gereken öğeleri, suç dolayısıyla sorumluluk için aranan koşulları, suç dolayısıyla uygulanması gereken yaptırımları, bu yaptırımların infaz suretlerini ve bu yaptırımlara mahkumiyete bağlanan hukuki sonuçları inceler. Maddi ceza hukuku kapsamında ayrıca, kanunlarda yer verilen suç tanımları ile ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulunulur.

Ceza muhakemesi hukuku ise, bir suçun belli bir kişi veya kişiler tarafından işlenip işlenmediği hususundaki maddi gerçeğin araştırılmasına ve ilgili kişi veya kişiler hakkında yapılabilecek işlemler ve verilebilecek kararlarla ilgili esas ve usullerin, bu sürece katılabilecek kişilerin hak, görev ve yetkilerinin belirlendiği bir bilim disiplini. Bu bakımdan, ceza muhakemesi hukuku, bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç, suç teşkil eden bir fiilin belli bir kişi veya kişiler tarafından işlendiği hususunda oluşan şüphe ile başlar ve bu şüphenin yenilmesine kadar devam eder. Söz konusu şüphe,

a) yapılan yargılama sonucunda, suçun belli kişi veya kişiler tarafından işlendiğinin sabit görülmesi ve bu nedenle ilgili kişi veya kişiler hakkında tesis edilen hükmün kesinleşmesi ile ya da

b) belli bir kişiyle bağlantılı olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma sonucunda, suçun bu kişi tarafından işlenmediğinin ya da kişi tarafından gerçekleştirilen fiilin suç oluşturmadağının anlaşılması üzerine verilen kararın kesinleşmesi ile

yenilir. Başka bir ifade ile, ceza muhakemesi süreci, suç teşkil eden bir fiilin belli bir kişi veya kişiler tarafından işlendiği hususunda oluşan şüphenin yenilmesiyle sona erer¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Doktrinde, ceza muhakemesi hukukunun, ceza hukuku altında bir bilim disiplini değil, ceza hukuku ile yakın ilişkileri olan “bağımsız” bir bilim dalı olduğu yönünde görüşler de ileri sürülmektedir (ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner: *Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı*,

Maddi ceza hukuku da kendi içinde **ceza hukuku genel hükümler** ve **ceza hukuku özel hükümler** olarak ikiye ayrılmaktadır.

Maddi ceza hukuku bilimi kapsamında öğrenciye okutulan **ceza hukuku genel hükümler** dersinde öğrenciye önce **ceza hukukuna girişle** ilgili bilgilere yer verilmektedir. Giriş kısmında, ceza hukukunun,

- a) hukuk bilim disiplinleri arasındaki yeri,
- b) diğer hukuk bilim disiplinleriyle olan ilişkisi,
- c) tarihsel ve teorik gelişimi,
- d) kaynakları,

ile ceza kanununun uygulama alanına ilişkin açıklamalarda bulunulur.

Ceza hukuku genel hükümler dersinin ikinci aşamasının konusunu, **suç teorisi** oluşturmaktadır. Suç teorisinde suçun yapısal unsurları, suçun yapısında bulunması gereken öğeler, suç dolayısıyla sorumluluk için aranması gereken koşullar ve suçun özel görünüş şekilleri incelenmektedir. Bu konulardaki inceleme ve açıklamalar yapılırken, önce, konuyla ilgili olarak ceza hukukunun teorik gelişimi sürecinde ileri sürülen önemli görüşler değerlendirilmektedir; metodolojik olarak, bilimsel bir yöntem izlenerek yapılan açıklamalar, aynı felsefi temele dayandırılmaktadır.

Ceza hukuku genel hükümler dersinin üçüncü aşamasında ise, öğrenciye **yaptırım teorisine** ilişkin bilgiler öğretilmektedir. Genel hükümler dersinin yaptırım teorisine ilişkin kısmında, suç oluşturan fiiller dolayısıyla uygulanabilecek ceza hukuku yaptırımlarının türleri, taşıdıkları özellikler, infaz suretleri ve bu yaptırımlara mahkumiyete bağlanan hukuki sonuçlar hakkında açıklamada bulunulur.

Son zamanlarda ülkemizdeki hukuk fakültelerinde, suç dolayısıyla uygulanabilecek ceza hukuku yaptırımlarına ve bunların infaz suretlerine ilişkin bilgilerin, bir ceza hukuku alt bilim disiplini olarak oluşturulmak istenen “**infaz hukuku**” adı altında öğretilmesine yönelik bir eğilim ortaya çıkmıştır. Ceza hukuku genel hükümler bilimi kapsamında yer verilen yaptırım teorisine ilişkin açıklamalar karşısında; hukuk fakültelerinde ayrıca “infaz hukuku” adı altında seçimlik de olsa bir ders okutulmasına gerek olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü, söz konusu ders kapsamında, ceza hukuku genel hükümler dersinde yaptırım teorisiyle ilgili olarak öğretilen konular öğrenciye sadece tekrar ettirilmektedir¹⁰⁷.

Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku, 7. bası, Ankara, 2013, Birinci Bölüm, §1, III, 3; İÇEL/DONAY[2], sh. 21).

¹⁰⁷ Doktrinde, “ceza infaz hukuku”nun, “bağımsız” bir bilim dalı olduğu yönünde görüşler de ileri sürülmektedir (İÇEL/DONAY(2), sh. 21; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, Birinci Bölüm, §1, III, 4).

Maddi ceza hukuku bilimi kapsamında öğrenciye okutulan **ceza hukuku özel hükümler** dersinde, suçlardan örnek olarak seçilen bazıları ile ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulunulur. Bu derste, öğrenciye, daha önce öğrendikleri suç teorisine ilişkin bilgilerin çeşitli suçlar bağlamıyla yapılan açıklama ve değerlendirmelerde nasıl kullanacakları öğretilerek uygulamaya hazırlanmaları sağlanır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, çeşitli kanunlarda yer alan düzenlemelere işlerlik kazandırabilmek amacıyla, belirlenen yükümlülüklerle aykırı davranışların suç olarak tanımlanması yoluna gidilmektedir. Bu bakımdan, örneğin (9.6.2004 tarihli ve 5187 sayılı) Basın Kanununda yer verilen ceza hukukuna ilişkin hükümlerle bağlantılı olarak “*Basın Ceza Hukuku*”, (4.1.1961 tarihli ve 293 sayılı) Vergi Usul Kanununda yer verilen ceza hukukuna ilişkin hükümlerle bağlantılı olarak “*Vergi Ceza Hukuku*” ibaresi kullanılmaktadır. Ceza hukukuna ilişkin hükümler içeren her kanunun ilişkin olduğu hukuk disiplininin hareketle örneğin “*Ticari Ceza Hukuku*”¹⁰⁸ gibi ayrı bir ceza hukukunun varlığından söz etmek doğru değildir¹⁰⁹.

¹⁰⁸ ERMAN, Sahir: *Ticari Ceza Hukuku I - Genel Kısım*, 5. bası, İstanbul, 1992.

¹⁰⁹ Kısmen doğru bulduğumuz bir görüş için bkz. İÇEL/DONAY(2), sh. 24.

Ş4. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla Olan İlişkisi

Ceza hukukunun temel prensipleriyle ilgili olarak, ceza kanunlarında hükümler bulunmasına rağmen, **Anayasa**'da da düzenlemeler yapılmıştır¹¹⁰. Bu düzenlemelerle, Anayasa koyucu, ilgili konuya verdiği önemi vurgulamaktadır¹¹¹.

Anayasa'da düzenlenen hak ve hürriyetlerin güvencesi olarak, bunları ihlal eden davranışlar, kanunlarda ve özellikle TCK'da suç olarak tanımlanmışlardır. Keza, TCK'da, Anayasa ile oluşturulan düzeni değiştirmeye ve bu düzenin işleyişini bozmaya yönelik cebir ve şiddet içeren fiiller suç olarak tanımlanmıştır¹¹². Bu bakımdan, ceza hukuku ile **anayasa hukuku** arasında önemli bağlantı bulunmaktadır¹¹³.

Ceza hukuku ile **devletler hukuku** arasında da yakın bir ilişki bulunmaktadır.

Suç olgusu her zaman sadece bir devletin ülkesinde gerçekleşmemektedir.

Kişi, bir ülkede suç işledikten sonra bir başka devletin ülkesine gitmiş olabilir. Bu durumda kişi, suçu işlediği ülke devleti tarafından, hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılabilmesi veya mahkûm olduğu cezanın infazı amacıyla, bulunduğu ülke devletinden iadesi, geri verilmesi istenebilir.

Şüpheli, sanık veya hükümlünün iadesine, geri verilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla devletler arasında “*suçluların iadesi*”ne ilişkin anlaşmalar imzalanmaktadır.

Keza, bir suç olgusuna ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için, devletler arasında işbirliği yapılmasına gerek duyulabilir. Bu ihtiyacı karşılamak, bu işbirliğine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla devletler arasında “*adli yardımlaşma*” sözleşmeleri imzalanmaktadır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kalpazanlık, insan ticareti ve terör (tedhiş) eylemleri gibi çoğu zaman sınır aşan suç örgütlerinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara karşı ortak mücadele verilebilmesini sağlamaya yönelik olarak devletler arasında daha etkin işbirliğine ilişkin esas ve usulleri belirleyen milletlerarası sözleşmeler bulunmaktadır.

Bu sözleşmelerle, taraf olan devletler, belirli fiilleri suç olarak tanımlamak, ceza hukukuna ilişkin etkin yaptırımlara bağlamak, bu suçlarla mücadele amacıyla

¹¹⁰ Bu düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi için ceza hukukunun kaynakları ile ilgili açıklamalara bakılmalıdır.

¹¹¹ SOYASLAN, Doğan: *Ceza Hukuku İle Diğer Hukuk Dalları ve Özellikle Anayasa Hukuku İlişkisi*, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Jale G. Akipek'e Armağan, Konya, 1991, sh. 111.

¹¹² Bkz. TCK, İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, Beşinci Bölüm altında yer alan suçlar.

¹¹³ Ceza hukukunun Anayasa hukuku ile ilişkisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÜNVER, Hukusal Değer, sh. 466 vd.

daha etkin işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak hususunda yükümlülük altına girmektedirler. Bu yükümlülüklerinin gereği olarak, taraf devletler mevzuatında, anayasa ve kanunlarında gerekli değişiklikleri yapmaktadırlar.

Ayrıca, bir devlette verilmiş olan mahkûmiyet hükmünün örneğin hükümlünün vatandaşı olduğu bir başka devlet ceza infaz kurumlarında çektirilmesini sağlamaya yönelik olarak milletlerarası anlaşmalar imzalanmaktadır.

Bütün bu sözleşmelerin imzalanıp yürürlüğe konulması ve hatta, bu sözleşmelerde belirlenen esas ve usullere göre uygulama yapılabilmesi, ceza hukuku ile devletler hukuku arasında yakın bir ilişki kurulmasını zorunlu kılmaktadır.

Ceza hukuku ile **idare hukuku** arasında da bağlantı bulunmaktadır.

TCK'da, kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini engellemeye yönelik fiillerin (m. 112, 113) yanı sıra, bu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen kamu görevlilerinin görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine duyulan güveni sarsıcı nitelikteki fiilleri (m. 247 vd.), suç olarak tanımlanmıştır. Bu suretle Ceza hukuku, yürütme ve idare görevinin hukuk zemininde yerine getirilmesini ve etkinliğini sağlama bakımından önemli bir fonksiyon icra etmektedir.

Eski ceza kanunlarında kabahat türünden suç olarak tanımlanmış olan fiillerin, zaman içerisinde, ceza kanunları kapsamından ve suç olmaktan çıkarılıp, idari yaptırımı gerektiren fiiller olarak ayrı bir kanunda düzenlenme yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu eğilimin etkisiyle, yeni TCK'da kabahat türünden suçlara yer verilmemiştir; idari yaptırımı gerektiren fiillerle ilgili olarak, "**Kabahatler Kanunu**" adıyla ayrı bir kanun kabul edilmiş ve yürürlüğe konmuştur¹¹⁴. Kabahatler Kanununun en önemli özelliği, ceza hukuku ile idare hukuku arasında bir ortak alan oluşturmastır. Kabahatler karşılığında öngörülen idari yaptırımlara, prensip olarak, idari kurul, makam veya kamu görevlileri tarafından karar verilmektedir (5326 s. Kanun, m. 22, f. 1, 2). Ancak, Kabahatler Kanunu, idari yaptırım kararı verilirken uyulması gereken esaslar bakımından TCK'nın genel hükümler kısmındaki düzenlemelere yollama yapması dolayısıyla, ceza hukuku ile sıkı bir ilişki içinde bulunmaktadır.

Keza, kamu görevlilerinin bir idari faaliyetin icrası sırasında işlediği suç oluşturan fiil, aynı zamanda disiplin yaptırımı uygulamasını da gerektirebilir. Bu bakımdan da ceza hukuku ile idare hukuku arasında önemli bağlantı noktaları bulunmaktadır.

Ceza hukuku ile **medeni hukuk** arasında da yakın bir ilişki bulunmaktadır. Zira, TCK'nın Özel Hükümler Kitabında yer alan pek çok suç tanımı, **Türk Medeni Kanununun** düzenleme alanına giren kişilik haklarının, malvarlığı haklarının ve ailenin korunmasını amaçlamaktadır. Keza, çeşitli suç tanımlarında yer

¹¹⁴ 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (RG: 31 Mart 2005/25772).

alan kan ve kayın¹¹⁵ hısımlığına ilişkin kavramların içeriği Medeni Kanun hükümlerine göre belirlenmektedir.

Ceza hukuku ile medeni hukukun bir alt bilim disiplini oluşturduğu **borçlar hukuku** arasında büyük ölçüde kavram birliği mevcuttur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, hukuka aykırılık kavramının anlam, içerik ve kapsamı bakımından ceza hukuku, medeni hukuk ve hatta, bütün hukuk disiplinleri arasında bir müştereklik bulunmaktadır.

Suç teorisi bağlamında yapılan açıklamalar ile, borçlar hukuku genel hükümler kapsamında haksız fiil kavramının yapısal unsurlarına ilişkin açıklamalar arasında, izlenen teorik düşünceden kaynaklanan farklılıklar bir yana, önemli benzerlikler vardır.

Keza, suç oluşturan ve dolayısıyla, ceza hukuku yaptırımını uygulanmasını gerektiren fiiller, aynı zamanda haksız fiil niteliği taşıdığı için, **Borçlar Kanununun** haksız fiil nedeniyle tazminat sorumluluğuna ilişkin hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. Bu bakımdan ceza hukuku ile borçlar hukuku arasında yakın bir ilişki mevcuttur.

Kriminoloji (suç bilimi) suçun işlenme nedenlerini, suçun işlenişinin arzettiği özellikleri deneysel (tecrübî, ampirik) yöntemle inceleyen bir bilim dalıdır¹¹⁶. Kriminoloji, suçun işlenmesi üzerinde etkili olan nedenleri araştırır. Kişinin içinde yaşadığı sosyal çevre şartlarının, aile ilişkilerinin, ekonomik durumunun, eğitim durumunun, cinsiyetinin, yaşının, dini inanışlarının, psikiyatrik, psikolojik ve hatta biyolojik özelliklerinin ve keza, iklim ve mevsim gibi doğal çevre koşullarının, doğal ve sosyal felaketlerin, suç işleme olgusu üzerindeki etkilerini araştırmak; kriminoloji biliminin iştigal konularını oluşturmaktadır.

Ceza hukuku *normatif* bir bilim dalıdır. Buna karşılık, yukarıda da belirttiğimiz gibi, kriminoloji, *deneysel (tecrübî, ampirik)* yöntemin kullanıldığı bir bilim dalıdır. Bu bakımdan, kriminoloji, büyük ölçüde alan taramasını ve anket çalışmasını gerektirmektedir.

Kriminoloji bilimi sayesinde ulaşılan veriler, ülkede izlenmesi gereken suç ve ceza siyasetinin belirlenmesinde büyük bir önemi haiz bulunmaktadır¹¹⁷. Ancak,

¹¹⁵ “Kayın” ibaresinin doğrusu “**kaim**”dir. Kaim, **asilin yerine geçen** anlamına gelmektedir. Ancak bu ibare Türkçede yaygın bir şekilde “kayın” olarak kullanılmaktadır.

¹¹⁶ AKINCI, Füsün Sokullu: *Kriminoloji*, İkinci bası, İstanbul, 1999, sh. 22, 23; SOYASLAN, Doğan: *Kriminoloji (Suç ve Ceza) Dersleri*, Ankara, 1996, sh. 9, 10; DÖNMEZER, Sulhi, *Kriminoloji*, 8. bası, İstanbul, 1994, sh. 1 vd.; DEMİRBAŞ, Timur: *Kriminoloji*, Ankara, 2001, sh. 29, 30.

¹¹⁷ ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, Birinci Bölüm, §1, III, 5, A; CENTEL, Nur: *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, İstanbul, Kasım 2001, sh. 12; İÇEL/DONAY (2), sh. 24; YÜCEL, Mustafa Tören: *Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi, Suç ve Ceza*, Ankara, 1999, sh. 4 vd.

bu verilerin, aynı ülkede yapılan kriminolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkması gerekir. Bu itibarla, başka bir ülkede, sosyal dokusu farklı olan bir toplumda yapılmış olan kriminolojik araştırmalardan hareketle kanuni düzenleme yapılması, çoğu zaman beklenen faydayı sağlamaz.

Ceza hukukunun, hukuk bilim disiplinleri dışında başka bilim dalları ile de yakın ilişkisi mevcuttur. Özellikle maddi gerçeğin araştırılması, suç olayının açıklığa kavuşturulması ve suçluların tespiti bakımından tıp, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimlerinin verilerinden önemli ölçüde yararlanılmaktadır. Bu bakımdan fen bilimlerinin verilerinin adli vakaların aydınlatılmasında kullanılmasını ifade zımında **adli bilimlerden** (*forensic sciences*) söz edilmektedir. Örneğin tıp biliminin verilerinin adli vakaların aydınlatılmasında kullanılmasına ilişkin yöntemleri belirlemek üzere, tıbbın bir alt bilim dalı olarak, **adli tıp** (*forensic medicine, Forensische Medizin*) oluşturulmuştur. Keza, ceza muhakemesi sürecinde suç olgusunun açıklığa kavuşturulmasında ve suçluların tespitinde, tıp bilimi kadar, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimleri büyük bir katkı sağlamaktadır.

Bu amaçlara hizmet etmek üzere ülkemizde **Adli Tıp Kurumu** kurulmuş ve bu Kurumun belli merkezlerde şubeleri oluşturulmuştur. Keza, genel kolluk birimleri olan polis ve jandarma teşkilatı bünyesinde **kriminal laboratuvarlar** oluşturulmuştur.

§5. Türk Ceza Hukukunun Kaynakları

I. Doğrudan Kaynaklar

A. Anayasa

Ceza hukukunun kaynaklarının başında, ülkemizde yürürlükte olan **Anayasa** gelmektedir.

18.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı Kanunla kabul edilen **Türkiye Cumhuriyeti Anayasası**'nda¹¹⁸, ceza hukukuna ilişkin kanuni düzenlemeler ve uygulama açısından dikkate alınması gereken önemli prensiplere yer verilmiştir. *Suçta ve cezada kanunilik ilkesi*¹¹⁹, *ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi*¹²⁰ ve *masumluk karinesi*¹²¹ bu bakımdan örnek olarak gösterilebilir¹²².

Keza, Anayasa'da ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin ilkelere de yer verilmiştir (m. 38, f. 1, 2)¹²³.

Anayasa'da, kişiye işlediği suç nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza hukuku yaptırımının uygulanamayacağı¹²⁴; yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı¹²⁵; “*genel müsadere cezası*”nın verilemeyeceği¹²⁶, basın ve

¹¹⁸ RG: 09 Kasım 1982/17863.

¹¹⁹ “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” (Anayasa, m. 38, f. 3).

Keza, Anayasa'da, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sadece *ekonomik hak ve hürriyetler* konusunda düzenleme yapılabileceği öngörülmüştür (m. 104, f. 17). Bu hükme göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, bir fiil suç olarak tanımlanamaz ve bir suç karşılığında uygulanabilecek olan cezanın türü ve miktarı belirlenemez.

¹²⁰ “Ceza sorumluluğu şahsidir.” (Anayasa, m. 38, f. 7).

¹²¹ “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” (Anayasa, m. 38, f. 4).

“... suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.” (Anayasa, m. 15, f. 2).

¹²² Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. SOYASLAN, Jale Akipek'e Armağan, sh. 105 vd.

¹²³ “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” (Anayasa, m. 38, f. 1).

“Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.” (Anayasa, m. 38, f. 2).

“... suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; ...” (Anayasa, m. 15, f. 2).

¹²⁴ “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” (Anayasa, m. 17, f. 3).

¹²⁵ “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” (Anayasa, m. 38, f. 8).

¹²⁶ “... genel müsadere cezası verilemez.” (Anayasa, m. 38, f. 9).

yayın araçlarının müsadere edilemeyeceği¹²⁷, hüküm altına alınmıştır. Keza, bir ceza hukuku yaptırımı olarak “ölüm cezası” Anayasa ile kaldırılmıştır¹²⁸.

Anayasada devlete izafe edilen “insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya” ilişkin görevin (m. 5) gereği olarak; kişinin şahsiyetini serbestçe tekamül ettirebilmesi için “olmazsa olmaz şartı”nı (conditio sine qua non) oluşturan hak ve hürriyetlerin devlet eliyle güvence altına alınması gerekmektedir. Anayasada düzenlenen hak ve hürriyetlerin güvencesi olarak, bunları ihlal eden davranışlar, kanunlarda suç olarak tanımlanmışlardır.

Anayasa’da ceza muhakemesi hukuku bakımından da önemli ilkelere yer verilmiştir: Ceza muhakemesi sürecinde kişinin kendisinin veya yakınlarının aleyhine olarak açıklama yapmaya ve delil göstermeye zorlanamayacağı¹²⁹, kişiye işkence ve eziyet edilemeyeceği¹³⁰ ve keza, hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan delillerin hüküm kurulurken kullanılamayacağı¹³¹ açıkça belirtilmiştir.

Keza kişinin sahip bulunduğu hak ve hürriyetlere önemli ölçüde müdahaleyi gerekli kılan ceza muhakemesine ilişkin kanuni düzenlemeler, Anayasanın bu hak ve hürriyetlere yönelik olarak getirdiği sınırlama ölçütleri¹³² göz önünde bulundurularak yapılmaktadır¹³³.

¹²⁷ “Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez.” (Anayasa, m. 30).

¹²⁸ “Ölüm cezası ... verilemez.” (Anayasa, m. 38, f. 9).

¹²⁹ “Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.” (Anayasa, m. 38, f. 5).

¹³⁰ “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ... muameleye tabi tutulamaz.” (Anayasa, m. 17, f. 3).

¹³¹ “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.” (Anayasa, m. 38, f. 6).

¹³² “Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.” (Anayasa, m. 19, f. 3).

“Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çıkarılınca kadar bildirilir.” (Anayasa, m. 19, f. 4).

“Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hakim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir.” (Anayasa, m. 19, f. 5).

“Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.” (Anayasa, m. 19, f. 6).

“Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir.” (Anayasa, m. 19, f. 7).

“Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.” (Anayasa, m. 19, f. 8).

Anayasa’da iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı¹³⁴, tabii hakim ilkesi¹³⁵, hakim ve mahkemelerin bağımsızlığı¹³⁶ güvence altına alındığı gibi; hakimlik ve savcılık teminatı¹³⁷ ile duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması gerektiği¹³⁸ hususunda hükümlere yer verilmiştir.

Ancak, belirtmek gerekir ki, Anayasa’da hakaret suçu bağlamında isnadın ispatı ile ilgili hükme yer verilmiştir¹³⁹. Başka anayasalarda örneği bulunmayan bu hükme Anayasa’da yer verilmesinin gereksiz olduğunu düşünmekteyiz. Hatta, Anayasa’nın bu konudaki düzenlemesinde teknik ceza hukuku bakımından bazı hatalar da bulunmaktadır.

“Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.” (Anayasa, m. 17, f. 10).

Ayrıca, arama ve elkoyma yetkisi bakımından bkz. Anayasa, m. 20, f. 2; m. 21, f. 1, m. 28, f. 8; haberleşme içeriklerinin öğrenilmesi ve telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenmesi bakımından bkz. Anayasa, m. 22, f. 2; şüpheli veya sanığın yurt dışına çıkış yasağı ile ilgili olarak bkz. Anayasa, m. 23, f. 3; süreli ve süresiz yayınların toplatılmasıyla ilgili olarak bkz. Anayasa, m. 28, f. 7.

¹³³ 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun koruma tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri (m. 90 vd.) Anayasanın bu hükümleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

¹³⁴ *“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”* (Anayasa, m. 36, f. 1).

¹³⁵ *“Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.”* (Anayasa, m. 37, f. 1).

“Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.” (Anayasa, m. 37, f. 2).

¹³⁶ *“Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.”* (Anayasa, m. 138, f. 1).

“Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” (Anayasa, m. 138, f. 2).

“Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.” (Anayasa, m. 138, f. 3).

“Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” (Anayasa, m. 138, f. 4).

Kanaatimizce, organ olarak Yasamanın mahkeme kararlarına uymak gibi bir zorunluluğundan söz edilemez. Yasama organı (Türkiye Büyük Millet Meclisi), alacağı kararlarda mahkeme kararlarını sadece göz önünde bulundurur. Bu itibarla Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama organını da bağlayıcı etkisi olduğu yönündeki Anayasa hükmünün (m. 153, f. 6) doğru olmadığını düşünmekteyiz. Anayasa Mahkemesi kararları yasama organının karar alma sürecinde sadece göz önünde bulundurulabilmelidir.

¹³⁷ Bkz. Anayasa, m. 139, 140.

¹³⁸ Bkz. Anayasa, m. 141.

¹³⁹ Bkz. Anayasa, m. 39.

B. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar

I. Türk Ceza Hukukunun Anayasadan sonra en önemli kaynağını Türk Ceza Kanunu oluşturmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk ceza kanunu, **1 Mart 1926** tarihinde **765** sayılı ile kabul edilen **Türk Ceza Kanunu**'dur. Ancak, bu Kanun, 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır (5252 s. K., m. 12, f. 1, bent b).

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından **26 Eylül 2004** tarihinde **5237** sayılı yeni bir **Türk Ceza Kanunu** kabul edilmiş ve bu Kanun, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İşaret etmek gerekir ki, 765 s. TCK, 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla ilga edilmiş ise de, zaman bakımından uygulama kurallarının gereği olarak lehe hüküm taşıdığı hallerde 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş olan suçlarla ilgili olarak da uygulanmaya devam edecektir. Bu bakımdan, söz konusu Kanun da Türk Ceza Hukukuna bir süre daha kaynaklık etmeye devam edecektir.

II. Türk Ceza Hukukuna kaynaklık eden üçüncü kanun, 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'dur. Söz konusu Kanun, münhasıran Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında uygulanabilen, bu kişilerin görevleriyle bağlantılı olarak işleyebilecekleri suçların tanımlandığı ve bu suçlara ilişkin yaptırımların belirlendiği özel bir kanuna olan ihtiyaca binaen vazedilmiştir.

III. 4.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Söz konusu Kanun, 5237 s. TCK'nın yürürlüğe girmesinin ve 765 s. TCK'nın yürürlükten kaldırılmasının ortaya çıkarabileceği uygulama sorunlarına çözüm getiren geçiş hükümleri içermektedir.

IV. 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu. Bir suç olayına ilişkin şüphenin ortaya çıkmasıyla başlayan ve bu şüphenin yenilmesine kadarki sürece, bu sürecin işleyişine ilişkin hükümler içeren CMK, aynı zamanda maddi ceza hukukuna da belli hususlarda kaynaklık etmektedir. Görevle bağlantılı olarak yetki kullanılması, görevin yerine getirilmesi hukuka uygunluk nedenini oluşturmaktadır. Hukuka uygun olan bu fiil dolayısıyla kişiye ceza verilemeyeceği tartışmasızdır. Ceza muhakemesi sürecinde, bu sürece katılan sùjeler (kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı, hakim, müdafii, vekil, bilirkişi, tanık vs.) bazı yetkiler kullanmaktadırlar. Bu yetkilerin kullanılması bağlamında gerçekleştirdikleri fiiller, hukuka uygun fiillerdir. Dolayısıyla, CMK, ceza muhakemesi sürecine katılan kişilerin görevleriyle bağlantılı olarak kullanabilecekleri yetkilerin kapsam ve sınırlarını belirlerken, bu görevlerle bağlantılı olarak TCK'daki görevin yerine getirilmesi hukuka uygunluk nedeninin koşullarına açıklık getirmektedir.

Keza, CMK'nın 223. maddesinde yer alan, yapılan yargılama sonucunda mahkemenin beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verebileceği hallere

ilişkin hükümler, 5237 s. TCK'nın hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu etkileyen nedenlerle ilgili olarak benimsediği ayırıma açıklık getiren bir içerik taşımaktadır.

V. 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun. TCK'da tanımlanan suçlara ilişkin olarak öngörülen yaptırımların ne suretle infaz edileceği bu Kanunda belirlenmiştir. Hapis cezasının ne suretle infaz edileceğine, bu bağlamda infazı bakımından koşullu salıverilmeye ve adli para cezasının ne suretle infaz edileceğine ilişkin hükümler, bu Kanunda yer almaktadır. Keza, belirli hükümlülere ilişkin hapis cezaları ile çeşitli kısa süreli hapis cezalarının infaz biçimleri, bu Kanunda düzenlenmiştir.

Yeni İnfaz Kanununun yürürlüğe girmesiyle **“13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ... yürürlükten kaldırılmıştır.”** (5275 s. K, m. 122). Ancak, işaret etmek gerekir ki, söz konusu 647 s. Kanun, 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla ilga edilmiş ise de, zaman bakımından uygulama kurallarının gereği olarak lehe hüküm taşıdığı hallerde 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş olan suçlarla ilgili olarak da uygulanmaya devam edecektir. Bu bakımdan, söz konusu Kanun da Türk Ceza Hukukuna bir süre daha kaynaklık etmeye devam edecektir.

VI. 23.3.2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Söz konusu Kanun, 5271 s. CMK'nın yürürlüğe girmesine karşılık, 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı **“Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu”** ile usul hükümleri içeren sair kanunların yürürlükten kaldırılmasının ortaya çıkarabileceği uygulama sorunlarına çözüm getiren geçiş hükümleri içermektedir.

VII. 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu. 765 s. mülga TCK'nın aksine, yeni TCK'da suçlar “cürüm” ve “kabahat” olarak bir ayırıma tabi tutulmamıştır. Dolayısıyla, TCK'da “bir suç türü” olarak “kabahat”e yer verilmemiştir. Ancak, bu durum, suç oluşturmamakla birlikte haksızlık ifade eden belirli fiillerin kabahat olarak tanımlandığı ve bu haksızlıklarla ilgili genel hükümlerin yer aldığı ayrı bir kanuna ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Kabahatler Kanunu, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla konulmuştur.

Keza, kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarının kapsamından çıkarma eğiliminin bir sonucu olarak; çeşitli hususlarda düzenleme getiren özel kanunlarda bazı fiiller karşılığında idari yaptırımlar öngörülmektedir. Bu fiiller karşılığında, genellikle parasal nitelikte bir yaptırım öngörülmektedir. Ancak, bu parasal yaptırım, bir ceza hukuku yaptırımı olan "adli para cezası" değil; idari yaptırım olarak "idari para cezası" niteliği taşımaktadır. Her ikisi de belli bir miktar paranın kişiden alınıp Devlet Hazinesine intikalinden ibaret gibi görünürse de; adli nitelikteki para cezası ile idari nitelikteki para cezası arasında, karar veren merci, yaptırımın infaz sureti, yaptırıma bağlanan hukuki sonuçlar bakımından önemli

farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle ekonomik hayata ilişkin düzenlemelerin yapıldığı kanunlarda oldukça sık bir şekilde idari nitelikte yaptırımlara yer verilmektedir. Çeşitli kanunlara dağılmış, idari nitelikteki bu yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ve bunların yerine getirilmesine ilişkin kazuistik düzenlemelerden sarfınazar edilip, yeknesak hükümlerin yer aldığı bir kanuna duyulan ihtiyaç bu suretle karşılanmıştır.

VIII. 25.5.2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu. Yeni Türk Ceza Kanununun kabulüyle 765 sayılı Kanundan farklı bir yaptırım rejimi benimsenmiştir. Bu sistemde, ceza hukuku yaptırımı olarak ceza ve güvenlik tedbiri ayırımına yer verilmiştir. Cezalar, hapis ve adli para cezası olarak bir ayırıma tabi tutulmuştur. Böylece, yeni TCK'da, 765 sayılı Kanunda benimsenen asli ceza ve fer'i ceza ayırımı ve bu Kanundan farklı olarak, belli bir suçtan mahkumiyete bağlı olarak kişiyi ömür boyu belli haklardan yoksun bırakacak yaptırım sistemi terkedilmiştir. Yeni Adli Sicil Kanunu, yeni TCK'da benimsenen bu yaptırım sistemine uyum sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.

IX. 3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu. Çocukların içinde bulundukları koşullardan dolayı suça sürüklendikleri gerçeğinden hareketle, özel korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasını, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını, toplumun adalet ve güvenlik ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen çocuk adalet sisteminin esas ve usullerini düzenlemek amacıyla, söz konusu Kanun çıkarılmıştır.

X. 3.7.2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu. Bu Kanun, özellikle hapis cezasının infazı ile bağlantılı ya da müstakil bir güvenlik tedbiri olarak denetimli serbestlik tedbirinin ne suretle infaz edileceğine ilişkin hükümler içermesi bakımından, Türk Ceza Hukukuna kaynaklık etmektedir.

XI. 23.04.2016 tarihli ve 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu. Bu Kanunda, cezaî konularda uluslararası adli işbirliğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

XI. Ceza hukukuna ilişkin hükümler sadece bu kanunlarda bulunmamaktadır. Pek çok kanunda düzenledikleri alanlarla ilgili olarak çeşitli suç tanımlarına yer verilmiştir. Bu bakımdan, suç tanımı içeren her bir kanun da Türk Ceza Hukukunun ayrı bir kaynağını oluşturmaktadır¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Bu kanunlardan başlıcaları, örnek olarak aşağıya alınmıştır:

- 1) 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı *Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun*,
- 2) 14.5.1928 tarihli ve 1262 sayılı *İспенçiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu*,
- 3) 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı *Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun*,
- 4) 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı *Umumi Hıfzıssıhha Kanunu*,
- 5) 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı *Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun*,

- 6) 16.7.1943 tarihli ve 4473 sayılı *Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun*,
- 7) 10.6.1946 tarihli ve 4922 sayılı *Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun*,
- 8) 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı *Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun*,
- 9) 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu*,
- 10) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı *Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun*,
- 11) 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı *Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun*,
- 12) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı *Orman Kanunu*,
- 13) 15.5.1957 tarihli ve 6968 sayılı *Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu*,
- 14) 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı *Tebliğat Kanunu*,
- 15) 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı *Sigorta Murakabe Kanunu*,
- 16) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı *Vergi Usul Kanunu*,
- 17) 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı *Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun*,
- 18) 24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı *Kooperatifler Kanunu*,
- 19) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı *Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu*,
- 20) 6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı *Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu*,
- 21) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı *Karayolları Trafik Kanunu*,
- 22) 1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı *Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu*,
- 23) 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı *Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu*,
- 24) 3.6.1986 tarihli ve 3298 sayılı *Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun*,
- 25) 11.1.1989 tarihli ve 3516 sayılı *Ölçüler ve Ayar Kanunu*,
- 26) 4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı *Kıyı Kanunu*,
- 27) 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı *Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu*,
- 28) 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı *Terörle Mücadele Kanunu*,
- 29) 28.3.2001 tarihli ve 4632 sayılı *Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu*,
- 30) 1.7.2003 tarihli ve 4915 sayılı *Kara Avcılığı Kanunu*,
- 31) 15.1.2004 tarihli ve 5070 sayılı *Elektronik İmza Kanunu*,
- 32) 9.6.2004 tarihli ve 5187 sayılı *Basın Kanunu*,
- 33) 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı *Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun*,
- 34) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı *Bankacılık Kanunu*,
- 35) 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı *Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu*,
- 36) 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı *İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun*,
- 37) 27.12.2007 tarihli ve 5726 sayılı *Tanık Koruma Kanunu*,
- 38) 14.12.2009 tarihli ve 5941 sayılı *Çek Kanunu*,
- 39) 18.3.2010 tarihli ve 5977 sayılı *Biyogüvenlik Kanunu*,
- 40) 17.2.2011 tarihli ve 6114 sayılı *Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun*,

C. Milletlerarası Sözleşmeler

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan milletlerarası anlaşmalar da Türk ceza hukukuna kaynaklık etmektedir. Ceza hukuku uygulamasını yakından ilgilendiren pek çok hususta milletlerarası anlaşmalarda düzenlemeler yer almaktadır.

Milletlerarası anlaşmalarda yer alan hükümlerden bir kısmı, ayrıca iç hukukta bir kanuni düzenlemeye gerek olmaksızın doğrudan uygulanabilir niteliktedir. Bu tür düzenlemelere, Türkiye'nin taraf olduğu suçluların iadesine ve ceza işleminde karşılıklı adli yardıma ilişkin iki veya çok taraflı sözleşmelerde yer alan hükümlerin büyük bir kısmını, örnek olarak göstermek mümkündür.

Ancak, bazı anlaşmalarda yer alan hükümlerin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla, anlaşmalarda yer alan hükümlerin iç hukuka yansıtılmasını sağlamaya yönelik olarak, ayrıca kanuni düzenlemeler yapılmasına gerek duyulmaktadır.

Örneğin, idam cezasının kaldırılmasını sağlamaya yönelik milletlerarası sözleşmeleri Türkiye'nin onaylamasının yanı sıra, çeşitli suçlar karşılığında idam cezası öngören kanuni düzenlemeleri değiştiren kanunlar çıkarılmasına ayrıca ihtiyaç duyulmuştur.

Keza, ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında şüpheli ve sanık konumunda bulunan kişilere milletlerarası anlaşmalarla sağlanan hakların iç hukuk uygulamalarında kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla, bu anlaşmaların onaylanarak yürürlüğe konmasının yanı sıra, kanunlardaki düzenlemelerde de taraf olunan sözleşmelerde yer alan hükümler doğrultusunda değişiklikler yapılması gereği vardır.

Türkiye'nin de taraf olduğu, terörizmin önlenmesine yönelik milletlerarası sözleşmelerle yüklenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla iç hukukta çeşitli kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, bazı suçların yurt dışında işlenmiş, fail ve mağdurunun yabancı olması dolayısıyla yaptırımsız kalmasının önüne geçilmesi amacıyla, milletlerarası sözleşmeler-

41) 31.3.2011 tarihli ve 6222 sayılı *Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun*,

42) 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı *Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun*,

43) 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı *Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu*,

44) 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı *Sermaye Piyasası Kanunu*,

45) 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı *Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun*,

46) 4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı *Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu*,

47) 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu*,

48) 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı *Sınai Mülkiyet Kanunu*,

49) 27.12.2020 tarihli ve 7262 sayılı *Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun*.

den kaynaklanan yükümlülüklerin gereği olarak TCK’da düzenlemeler yapılmıştır (m. 13). Keza, “karapara”nın aklanmasının önlenmesi amacıyla yönelik olarak, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” (m. 282) suçu tanımı yapılmıştır. Aynı şekilde, 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda “terörizmin finansmanı” suçu tanımına yer verilmiştir (m. 4).

Ceza hukukuna ilişkin hükümler içeren milletlerarası sözleşmelerdeki hükümlerin, “temel hak ve özgürlüklere ilişkin” düzenlemeler olduğu kuşkusuzdur. Bu bakımdan, Anayasanın 90. maddesinin beşinci fıkrasında, 7.5.2004 tarihli ve 5170 sayılı Kanunla (m. 7) yapılan değişiklik, büyük bir önem taşımaktadır:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

Buna göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş olmasına rağmen, milletlerarası sözleşmelerdeki ceza hukukuna ve dolayısıyla “temel hak ve özgürlüklere ilişkin” hükümlere paralel olarak kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde, uygulamada milletlerarası sözleşmelerdeki hükümler esas alınacaktır. Yani bu durumda, iç hukuk metni olan kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

Bu nedenle, taraf olunan milletlerarası sözleşmeler hükümlerine paralel olarak kanunlarda da ayrıca düzenleme yapılmasına gerek olsa bile, Anayasanın bu hükmü karşısında, milletlerarası sözleşmelerin, Türk ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında zikredilmesi gerektiği kanısındayız¹⁴¹.

Ceza hukukuna kaynaklık görevi yapan ve Türkiye’nin taraf olduğu başlıca milletlerarası sözleşmeler, sıralamada metinlerin yayımlandığı Resmi Gazete tarihleri esas alınarak, aşağıya liste halinde çıkarılmıştır¹⁴²:

1) Genocide’nin Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme (09.12.1948, Paris)¹⁴³.

¹⁴¹ Türk hukukunda milletlerarası sözleşmeler ile kanunlar arasındaki ilişki ve milletlerarası sözleşmelerin doğrudan uygulanabilirliği ile ilgili olarak bkz. BAYTEMİR KONTACI, Burcu: *Ceza Hukukunun Uluslararasılaşması ve Ulusal Ceza Hukuku Sistemleri: Türk Ceza Hukuku Özelinde Bir İnceleme*, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019, sh. 49, vd.

¹⁴² Söz konusu sözleşme metinleri bir bütün olarak, Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi yayını olan “**Türk Ceza Hukuku Mevzuatı**, Cilt 3 (Milletlerarası Sözleşmeler), Ankara, Nisan 2017” künyeli kitapta yayımlanmıştır.

¹⁴³ Sözleşme metni, 26 Mart 1950 tarihli ve 7469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

- 2) **İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme** (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 4 Kasım 1950, Avrupa Konseyi)¹⁴⁴.
- 3) **Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi** (Avrupa Konseyi, Paris, 13.12.1957)¹⁴⁵.
- 4) **Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme**¹⁴⁶
- 5) **Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi** (30 Mart 1961)¹⁴⁷.
- 6) **Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi** (Avrupa Konseyi, Strazburg, 20.04.1959, ETS No: 30)¹⁴⁸.
- 7) **Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme** (16.12.1970, La Haye)¹⁴⁹.
- 8) **Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme** (23.09.1971, Montreal)¹⁵⁰.
- 9) **Uçaklara Karşı İşlenen Suçlara ve Diğer Fiillere İlişkin Sözleşme** (14.09.1963, Tokyo)¹⁵¹.
- 10) **Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi** (Avrupa Konseyi)¹⁵².
- 11) **Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi** (Avrupa Konseyi)¹⁵³.
- 12) **Psikotrop Maddeler Sözleşmesi** (21.2.1971, Viyana)¹⁵⁴.
- 13) **Tedhişçiliğin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi** (Avrupa Konseyi, 27.1.1977, Strazburg)¹⁵⁵.
- 14) **Diplomasi Ajanları Da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korumaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme** (Birleşmiş Milletler, 14.12.1973, New York)¹⁵⁶.

¹⁴⁴ Sözleşme metni, 19 Mart 1954 tarihli ve 8662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁴⁵ Sözleşme metni, 26 Kasım 1959 tarihli ve 10365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁴⁶ Söz konusu Sözleşme metni ile bu Sözleşmenin onaylanmasına ilişkin 29.8.1961 tarihli ve 359 sayılı Kanun, 5 Eylül 1961 tarih ve 10898 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁴⁷ Sözleşme metni, 12 Mayıs 1967 tarihli ve 12596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁴⁸ Sözleşme metni, 16 Ekim 1968 tarihli ve 13028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁴⁹ Sözleşme metni, 31 Mart 1973 tarihli ve 14493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵⁰ Sözleşme metni, 29 Kasım 1975 tarihli ve 15427 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵¹ Sözleşme metni, 8 Aralık 1975 tarihli ve 15436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵² Sözleşme metni, 14 Aralık 1977 tarihli ve 16139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵³ Sözleşme metni, 27 Aralık 1977 tarihli ve 16152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵⁴ Sözleşme metni, 7 Mart 1981 tarihli ve 17272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵⁵ Sözleşme metni, 26 Mart 1981 tarihli ve 17291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵⁶ Sözleşme metni, 1 Mayıs 1981 tarihli ve 17327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

- 15) **Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi** (Avrupa Konseyi, 19.06.1985)¹⁵⁷.
- 16) **İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi** (26 Kasım 1987)¹⁵⁸.
- 17) **İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi** (10 Şubat 1984)¹⁵⁹.
- 18) **Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol** (Avrupa Konseyi, Strazburg, 17.3.1978, ETS No: 99)¹⁶⁰.
- 19) **Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol** (Avrupa Konseyi, 17.3.1978)¹⁶¹.
- 20) **Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi** (14.09.1990)¹⁶².
- 21) **Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi** (20.12.1988)¹⁶³.
- 22) **İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 2. Protokol** (Strazburg, 4 Kasım 1993)¹⁶⁴.
- 23) **Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişiklik (Sözleşmesi)** (12.12.1995)¹⁶⁵.
- 24) **Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi** (OECD, 17.12.1997, Paris)¹⁶⁶.
- 25) **Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması** (Birleşmiş Milletler, 26.05.1999, Bükreş)¹⁶⁷.
- 26) **Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokol** (25.03.1972)¹⁶⁸.

¹⁵⁷ Sözleşme metni, 13 Haziran 1987 tarihli ve 19486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵⁸ Sözleşme metni, 27 Şubat 1988 tarihli ve 19738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵⁹ Sözleşme metni, 10 Ağustos 1988 tarihli ve 19895 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁶⁰ Protokol metni, 18 Ocak 1990 tarihli ve 20406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁶¹ Protokol metni, 25 Eylül 1991 tarihli ve 21002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁶² Sözleşme metni, 27 Ocak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁶³ Sözleşme metni, 11 Şubat 1996 tarihli ve 22551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁶⁴ Protokol metni, 23 Haziran 1997 tarihli ve 23028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁶⁵ Değişiklik Sözleşmesinin metni, 13 Ekim 1999 tarihli ve 23845 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁶⁶ Sözleşme metni, 10 Mayıs 2000 tarihli ve 24045 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁶⁷ Anlaşma metni, 05 Kasım 2000 tarihli ve 24221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁶⁸ Protokol metni, 30 Haziran 2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

- 27) **Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme** (Birleşmiş Milletler, 09.12.1999, New York)¹⁶⁹.
- 28) **Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme** (Birleşmiş Milletler, 20.05.1999, New York)¹⁷⁰.
- 29) **Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme** (Birleşmiş Milletler, 13.10.1972, New York)¹⁷¹.
- 30) **Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol** (Birleşmiş Milletler, 08.09.2000, New York)¹⁷².
- 31) **Sınırışan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi** (Birleşmiş Milletler, 13.12.2000, Palermo)¹⁷³.
- 32) **Sınırışan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol** (Birleşmiş Milletler, 13.12.2000, Palermo)¹⁷⁴.
- 33) **Sınırışan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol** (Birleşmiş Milletler, 13.12.2000, Palermo)¹⁷⁵.
- 34) **Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi** (Avrupa Konseyi, 27.09.2001 Strazburg)¹⁷⁶.
- 35) **Medenî ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme** (Birleşmiş Milletler, 15.08.2000, New York)¹⁷⁷.
- 36) **11 Nolu Protokol İle Değişik İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 No.lu Protokol** (Avrupa Konseyi, 15.01. 2003, Strazburg)¹⁷⁸.
- 37) **Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi** (Avrupa Konseyi, 27.09.2001 Strazburg)¹⁷⁹.

¹⁶⁹ Sözleşme metni, 01 Nisan 2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷⁰ Sözleşme metni, 17 Nisan 2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷¹ Sözleşme metni, 16 Haziran 2002 tarihli ve 24787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷² Protokol metni, 28 Haziran 2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷³ Sözleşme metni, 18 Mart 2003 tarihli ve 25052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷⁴ Protokol metni, 18 Mart 2003 tarihli ve 25052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷⁵ Protokol metni, 18 Mart 2003 tarihli ve 25052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷⁶ Sözleşme metni, 17 Haziran 2003 tarihli ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷⁷ Sözleşme metni, 21 Temmuz 2003 tarihli ve 25175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷⁸ Protokol metni, 17 Eylül 2003 tarihli ve 25232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷⁹ Sözleşme metni, 02 Mart 2004 tarihli ve 25390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

- 38) **Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyarî Protokol** (Birleşmiş Milletler, 08.09.2000, New York)¹⁸⁰.
- 39) **Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi** (Avrupa Konseyi, 04.04.1997)¹⁸¹.
- 40) **Sınırşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamaları İle Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokol** (Birleşmiş Milletler, 28.06.2002)¹⁸².
- 41) **Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma** (26.02.2003, Brüksel)¹⁸³.
- 42) **Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme** (Avrupa Konseyi, 27.09.2001, Strazburg)¹⁸⁴.
- 43) **Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan Değişiklik İle Eki I., Tadil edilmiş II. ve IV. Protokoller** (26.03.1982)¹⁸⁵.
- 44) **Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü** (Avrupa Konseyi, 15.5.2003, Strazburg)¹⁸⁶.
- 45) **İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol** (Avrupa Konseyi, 09.01.2004, Strazburg)¹⁸⁷.
- 46) **Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol** (Birleşmiş Milletler, 03.02.2004, New York)¹⁸⁸.
- 47) **Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi** (10.12.2003)¹⁸⁹.

¹⁸⁰ Protokol metni, 18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸¹ Sözleşme metni, 20 Nisan 2004 tarihli ve 25439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸² Protokol metni, 26 Nisan 2004 tarihli ve 25444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸³ Anlaşma metni, 15 Haziran 2004 tarihli ve 25493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸⁴ Sözleşme metni, 01 Eylül 2004 tarihli ve 25570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸⁵ Sözleşme ve eki Protokoller metinleri, 04 Ocak 2005 tarihli ve 25690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸⁶ Protokol metni, 08 Nisan 2005 tarihli ve 25780 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸⁷ Protokol metni, 13 Aralık 2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸⁸ Protokol metni, 05 Ağustos 2006 tarihli ve 26250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸⁹ Sözleşme metni, 02 Ekim 2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

- 48) **Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi**¹⁹⁰.
- 49) **Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi**, (16.5.2005, Varşova) (ETS No: 196)¹⁹¹.
- 50) **Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi**, (11.5.2011, İstanbul) (ETS No: 210)¹⁹².
- 51) **“Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma”**¹⁹³.
- 52) **Avrupa Konseyi Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi**, (23.11.2001, Budapeşte) (ETS No: 185)¹⁹⁴.
- 53) **“İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'ye Değişiklik Getiren 15 No'lu Protokol”** (Strazburg, 24.6.2013) (CETS No: 213)¹⁹⁵.
- 54) **“Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”** (Strazburg, 28.1.1981) (ETS No: 108)¹⁹⁶.
- 55) **“Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokol”** (Strazburg, 18.12.1997) (ETS No: 167)¹⁹⁷.
- 56) **“Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi”** (Varşova, 16.05.2005) (ETS No: 197)¹⁹⁸.

¹⁹⁰ Sözleşme metni, 10 Eylül 2011 tarihli ve 28050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁹¹ Sözleşme metni, 13 Ocak 2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁹² Sözleşme metni, 08 Mart 2012 tarihli ve 28227 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Her ne kadar 19.3.2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (RG: 20 Mart 2021/31429) ile Türkiye söz konusu Sözleşmeden çekilmiş ise de; kanaatimizce, **usulde paralellik ilkesinin** gereği olarak, onaylanması Kanunla uygun bulunan bir Milletlerarası Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshedilmesi hukuken mümkün değildir. Söz konusu Sözleşmenin Türkiye bakımından feshedilmiş olduğu kabul edilse bile, bunun uygulamada hiçbir sonucu olmaz. Cumhurbaşkanının bu girişiminin, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri bakımından olumsuz bir izlenim oluşturmaktan başka bir etkisi olmaz.

Ancak, Avrupa Konseyi'nin resmi internet sitesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilciliğinin Konsey Genel Sekreterliğine 22.3.2021 tarihinde verdiği “SÖZLÜ NOTA”yla, Türkiye'nin söz konusu Sözleşmeden **çekildiğini** bildirmiş olduğu bilgisi yer almaktadır: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=declarations-by-treaty&numSte=210&codeNature=1&codePays=TUR> (erişim tarihi: 11.07.2021).

¹⁹³ Anlaşma metni, 2 Ağustos 2014 tarihli ve 29076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁹⁴ Sözleşme metni, 9 Ağustos 2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁹⁵ Sözleşme metni, 17 Mart 2016 tarihli ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁹⁶ Sözleşme metni, 17 Mart 2016 tarihli ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁹⁷ Protokol metni, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁹⁸ Sözleşme metni, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

- 57) “Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” (Varşova, 16.5.2005) (CETS No: 198)¹⁹⁹.
- 58) “11 No’lu Protokol ile Değişik İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye Ek 7 No’lu Protokol” (Strazburg, 22.11.1984) (ETS No: 117)²⁰⁰.
- 59) “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi’ne İkinci Ek Protokol” (Strazburg, 8.11.2001) (ETS No: 182)²⁰¹.
- 60) “Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol” (Strazburg, 15.10.1975) (ETS No: 86)²⁰².
- 61) “Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Üçüncü Protokol” (Strazburg, 10.11.2010) (CETS No: 209)²⁰³.
- 62) “Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Dördüncü Protokol” (Viyana, 20.9.2012) (CETS No: 212)²⁰⁴.
- 63) Avrupa Konseyi “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınaraşan Veri Akışına İlişkin Protokol” (Strazburg, 8.11.2001) (ETS No: 181)²⁰⁵.
- 64) “Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi” (Moskova, 28.10.2011) (CETS No: 211)²⁰⁶.
- 65) Avrupa Konseyi “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi’ne Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokol” (Paris, 12.1.1998) (ETS No: 168)²⁰⁷.
- 66) Birleşmiş Milletler “Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Sözleşme” (Pekin, 10.9.2010)²⁰⁸.

¹⁹⁹ Sözleşme metni, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰⁰ Protokol metni, 8 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰¹ Protokol metni, 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰² Protokol metni, 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰³ Protokol metni, 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰⁴ Protokol metni, 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰⁵ Protokol metni, 24 Mayıs 2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰⁶ Sözleşme metni, 2 Ağustos 2017 tarihli ve 30142 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰⁷ Protokol metni, 24 Ağustos 2017 tarihli ve 30164 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰⁸ Sözleşme metni, 24 Ağustos 2017 tarihli ve 30164 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

- 67) Birleşmiş Milletler “Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmeye Ek Protokol” (Pekin, 10.9.2010)²⁰⁹.
- 68) “Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi'ne Ek Protokol” (Riga, 22.10.2015) (CETS No: 217)²¹⁰.
- 69) Birleşmiş Milletler “Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokol” (Cenevre, 10.1.2013)²¹¹.
- 70) Birleşmiş Milletler “Havaaraçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesini Tadil Eden Protokol” (Montreal, 4.4.2014)²¹².
- 71) Birleşmiş Milletler “Kıta Sahanelerinde Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü” (Londra, 14.8.2016)²¹³.
- 72) “Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi” (Saint-Denis, 3.7.2016)²¹⁴.

II. Dolayısıyla Kaynaklar

Ceza hukukunun doğrudan kaynakları, somut olaya doğrudan uygulanabilen bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla kaynaklar ise, somut olaya doğrudan uygulanmamaktadır; aksine, doğrudan uygulanan örneğin bir kanun metninin içeriğinin anlaşılması ve yorumlanması hususunda bir kaynaklık görevi icra etmektedirler.

Doğrudan kaynakların hukuk uygulayıcıları bakımından bağlayıcı bir etkisi bulunmaktadır. Buna karşılık, dolaylı kaynakların ise, bağlayıcı olan bir etkisinden söz edilemez. Dolaylı kaynaklar, somut olayla ilgili olarak karar veren hakim tarafından göz önünde bulundurulur.

A. Yüksek Mahkeme Kararları

Mahkemelerin verdikleri kararlar, ancak ilişkin oldukları olaylarla ilgili olarak bir hukuki sonuç doğururlar. Bu nedenle, bir olayla ilgili olarak verilmiş olan

²⁰⁹ Protokol metni, 27 Ağustos 2017 tarihli ve 30167 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²¹⁰ Protokol metni, 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²¹¹ Protokol metni, 26 Mart 2018 tarihli ve 30372 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²¹² Protokol metni, 3 Kasım 2018 tarihli ve 30584 İkinci Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²¹³ Protokol metni, 19 Nisan 2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²¹⁴ Sözleşme metni, 30 Mart 2020 tarihli ve 31084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

bir mahkeme kararı, aynı nitelikte olan başka bir olayla ilgili olarak bağlayıcı bir sonuç meydana getiremez. Aynı durum, yüksek mahkeme ve dolayısıyla Yargıtay kararları bakımından da söz konusudur. Yargıtay içtihatları, belli bir kanun hükmünün yorumunu, belli bir zamandaki hukuk anlayışını, hukuki değer ölçülerini göstermeleri bakımından önem taşımaktadırlar. Bir olayla ilgili olarak karar veren mahkeme, Yargıtay'ın benzer olaylara ilişkin içtihatlarını göz önünde bulundurabilir. Ancak, bu durum, benzer olaylarla ilgili olarak Yargıtay'ın vermiş bulunduğu kararların mahkemeleri bağlayıcı bir sonuç meydana getirdiği şeklinde anlaşılmamalıdır ve daha da önemlisi, bu anlayışı çağrıştıracak şekilde uygulama geliştirilmemelidir.

Ancak, 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 45. maddesinde “*İçtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar*” denilerek, hukuk sistemimiz bakımından bu hususta bir istisna kabul etmiştir (f. 5)²¹⁵.

İçtihadı birleştirme kararı, “*Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları veya Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulu ile bir ceza dairesi; Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi veya bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyumsuzluklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek*” üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından verilir (Yargıtay K, m. 16, f. 1, bent 5)²¹⁶.

Bir içtihadı birleştirme kararı, Yargıtay Kanununun 45. maddesinde belirlenen usulle, yine Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Keza, belirtmek gerekir ki, bir içtihadı birleştirme kararı, karara konu teşkil eden hususla ilgili olarak kanuni düzenleme yapılması halinde, işlevsiz kalabilir²¹⁷.

²¹⁵ “*Belli bir uyumsuzluğun çözülmesinin üstüne çıkarak, bütün uyumsuzluklarda uygulanacak normu belirten ve dolayısı ile yasama görevi niteliğinde olan (İçtihadı birleştirme kararı müessesesi,) kanundan da farklı olarak hakimleri bağladığı için hakimlerin bağımsızlığı esasına ters düş*”mektedir KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 11. bası, İstanbul 2000, no. 89, sh. 145).

²¹⁶ İçtihadı birleştirme kararları Resmi Gazetede yayınlanmaktadır (Yargıtay K, m. 58).

²¹⁷ Anayasa Mahkemesi, Yargıtay içtihadı birleştirme kararları ile ilgili olarak **ülkemiz gerçekleriyle bağdaşmayan** şu kararı vermiştir (12.6.1969, E.1968/38, K. 1969/34, RG: 29 Ocak 1970/13412):

“*İçtihadı birleştirme kararı, o zamana değin hukuk alanında hukuk kuralı olarak bulunmayan yeni bir kural koymayı erek edinmiş olan bir hukuk işlemi değildir. ... bir olayda uygulanacak olan hukuk kuralının hangisi olduğu yönünde verilen kararlar arasında çelişmeye düşülmesi veya bir olayda uygulanacak olan bir hukuk kuralının başka başka davalarda değişik biçimde yorumlanarak uygulanması söz konusu olur ise, ortaya atılan hukuk görüşlerinden hangisinin hukuka uygun bulunduğunu belirtmek üzere içtihadı birleştirme kararı ve-*

B. Doktrin

Ceza hukuku uygulamasında doktriner çalışmalar da kaynaklık görevi yapmaktadır. Ceza hukukunun hemen hemen her konusuyla ilgili olarak akademik ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yapılan tespit ve değerlendirmeler, varılan sonuçlar, hukuk uygulayıcıları tarafından takip edilmeli ve bir olayla ilgili olarak karar veren mahkeme tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.

rilmesi yoluna gidilir. Demek ki içtihadı birleştirme kararı, belli bir olay için yeni bir hukuk kuralı koymak ereği ile değil, ancak ve ancak belli bir olaya uygulanacak yasanın veya nesnel nitelikte olan tüzük ve yönetmelik kuralları gibi öbür hukuk kurallarından hangisinin, hangi anlamda uygulanacağı saptamak için verilir. Buna göre içtihadı birleştirme kararı yasa koyucu veya yetkisi içinde idare tarafından ortaya konulmuş bulunan nesnel hukuk kurallarının uygulanma biçimini gösteren ve bu bakımdan yenilik doğurucu nitelikte bulunmayan, ancak hukukî bir durumu açıklayan nitelikte bir hukuk işlemidir. Bundan ötürü bu işlem; genel, nesnel ve yenilik doğurucu nitelikte bir işlem olan yasa koyma işlemi ile bir tutulamaz ve içtihadı birleştirme karar veren Yargıtay'ca Türkiye Büyük Millet Meclisine özgü yasama yetkisinin kullanılmış ve böylece Anayasa'nın öngördüğü güçler ayrılığı ilkesinin çiğnenmiş olduğu ileri sürülemez.”

Anayasa Mahkemesine göre, “Yargıtay, bir içtihadı Birleştirme Kararı ile belli olayda hangi kuralın uygulanacağını veya uygulanacak kuralın ne anlama geldiğini saptar”maktadır.

Anayasa Mahkemesi bu kararında Yargıtay içtihadı birleştirme kararları ile ilgili olarak, “bağlayıcı nitelikteki yorum kararı” nitelendirmesinde bulunmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, hukukta “yorum kararı” diye bir karar türü bulunmamaktadır. Keza, bağlayıcılığı olan da sadece hükümdür. Bu nedenle, yorumun bağlayıcılığından söz edilemez.

Bu mülâhazalarla, hukuk sistemimizde Yargıtay içtihadı birleştirme kararı uygulamasına bir an evvel son verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Ş6. Türkiye’de Yeni Bir Ceza Kanunu Hazırlanmasını Gerektiren Nedenler ve Hazırlık Süreci

I. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda, yeni bir hukuk sistemi oluşturma ve yeni bir ceza kanunu kabul etme düşüncesi hakim olmuştu.

Bu düşünceyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından **1 Mart 1926 tarihinde 765 sayı** ile kabul edilen “**Türk Ceza Kanunu**”, 1889 İtalyan Ceza Kanunundan iktibas edilmişti.

Bu iktibasta, 1889 İtalyan Ceza Kanununun daha önce büyük bir kısmı itibarıyla Türkçe’ye tercüme edilmiş olmasının yanı sıra, “*döneminin en demokratik, insan hak ve özgürlüklerine en geniş yer veren kanun olması*” etkili olmuştu²¹⁸.

765 sayılı TCK, esas itibarıyla 1889 İtalyan CK’ndan iktibas edilmiş ise de; Kanuna “*millîlik*” (!) karakteri izafe eden bazı hükümler de içermekteydi. Örneğin, resmen akdedilmiş bir nikah olmadan “*dinî nikah*” yapmayı veya yaptırılmayı “suç” olarak tanımlayan 237. madde hükmü bu bağlamda zikredilebilir.

Bu ilave hükümlerin bir kısmı, 1274 (1858) **Ceza Kanunname-i Hümayunu**’ndan iktibas edilmişti. Erkeklerin kadın kılığına girerek kadınlara mahsus mahallere örneğin kadınlar hamamına girmesi fiilini suç olarak tanımlayan hüküm (m. 422), “*alacağım diye kandırıp kızlık bozma suçu*” (m. 423) ve “*fuhuş maksadıyla kadın oynatmak suçu*” (m. 420), bu konuda başlıca örnekleri oluşturmaktaydı.

19. yüzyıl ceza hukuku anlayışında suç teorisinin temelinde illiyet bağlantısı yer almakta idi ve suç teorisine ilişkin pek çok mesele illiyet bağlantısı ile açıklanmaya çalışılıyordu. Bu anlayışın ürünü olarak, öldürmek kastıyla hareket etmesine rağmen failce bilinmeyen bir sebebin etkisiyle ölüm neticesinin meydana gelmesi durumunda sorumluluğu düzenleyen bir hükme Kanunda yer verilmişti (m. 451).

Kanunun genel hükümlerle ilgili düzenlemelerinde eksiklikler mevcuttu. Örneğin, Kanunda suça “eksik” teşebbüsle bağlantılı olarak gönüllü vazgeçme konusunda hüküm mevcut iken, “tam” teşebbüsle bağlantılı olarak etkin pişmanlık (faal pişmanlık, faal nedamet) düzenlenmemişti. Keza, Kanunda aynı neviden fikrî içtima konusu düzenlenmemişti.

Kanunu tercüme eden kişilerin 1889 İtalyan Ceza Kanununun hazırlanışı sırasında esas alınan suç teorisine ilişkin görüşlere yeterince vakıf olmamaları nedeniyle, bazı madde metinlerinin içeriği anlaşılmasa bir surette ifade edilmişti (m. 45, 279). Farklı kişiler tarafından farklı zamanlarda kısım kısım tercüme

²¹⁸ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. DÖNMEZER, Sulhi: *Mukayeseli Hukukta Yasalaştırma Eğilimi ve İlkeleri*, in: Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü Kutlama Çalışmaları, Kolokyumlar ve Tartışmalar (14 Ocak 1981), (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını), sh. 16.

edilmiş olması dolayısıyla, Kanun metninde tercüme bozuklukları mevcut olduğu gibi, bir kavram bütünlüğünden de bahsedilemezdi²¹⁹.

Kanundaki pek çok hüküm, suç ve yaptırım teorisindeki gelişmeler karşısında artık eskimişti. Hatta bu hükümlerden bir kısmının yanlış olduğu anlaşılmıştır. Meselâ, Kilise hukukundan mülhem “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” hükmü (m. 44), artık bugün suç teorisinde değer izafe edilen bir hüküm niteliği taşımamaktadır. Keza, akıl hastalıklarıyla ilgili olarak Kanunda benimsenen “tam” veya “kısmî akıl hastalığı” şeklindeki ayırım (m. 46, 47), bugün psikiyatri biliminin verileri karşısında kabul görmemektedir.

1889 İtalyan Ceza Kanununda olduğu gibi, 765 sayılı TCK’da *objektif sorumluluk* hallerine yer verilmişti. Belli bir fiili işleyen kişi, bu suretle öngörmediği daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi durumunda bu neticeden de sorumlu tutulabilmektedir (m. 407, 439, 452, 473).

“Aslî faili belli olmayan” adam öldürme veya müessir fiil suçlarında bir nevi “*kollektif sorumluluk*” rejimi kabul edilmiştir (m. 463).

765 sayılı TCK, kabulünden itibaren bugüne kadar altmıştan fazla kanunla değişikliğe maruz bırakılmıştır. Kanun, bu değişikliklerle yeknesaklığını yitirmiş bulunmaktadır.

Yapılan değişikliklerden bir kısmında, Suç Teorisine ve ceza hukukuna ilişkin temel prensiplerle bağdaştırılamayan hükümler Kanuna konulmuştu. Örneğin, bazı suç tanımlarına konulan “*eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca*” (m. 264, f. 7; m. 536, f. 1 ve 2; m. 537, f. 1, 2 ve 3) veya “*suç daha ağır bir cezayı gerektirse bile ayrıca*” (m. 264, f. 6) şeklindeki ifadelerle, *bir fiilden dolayı kişinin iki defa cezalandırılabilmesinin yolu açılmıştı*²²⁰.

²¹⁹ Örneğin 279. maddede, ayırıcı kıtas belirtilmeksizin “*amme hizmeti*” (kamu hizmeti) ve “*amme vazifesi*” (kamu görevi) ayırımı yapılmış; buna karşılık, “*hidematı ammeden memnuiyet*” (kamu hizmetlerinden yasaklılık) yaptırımını düzenleyen 20. maddede bu kavramlar arasındaki ayırım göz ardı edilmiştir. Keza, 20 ve 31. maddelerde “*hidematı ammeden memnuiyet*” (kamu hizmetlerinden yasaklılık) yaptırımını genel olarak düzenlendikten sonra; bazı suç tanımlarında ayrıca “*memuriyetten müebbeden mahrumiyet cezası*” (m. 219), “*sürelî veya temellî olarak memuriyetten yoksun kalma cezası*” (m. 230) ve “*memuriyetten yoksun kılma*” yaptırımını (m. 240) öngörülmüştür. Keza, 279. maddede, ancak “*amme vazifesi*” gören kişilerin “*ceza kanununun tatbikatında memur*” sayılacağı belirtilmiş iken; bazı suç tanımlarında, “*memur*” (m. 202 vd., 339, 340), “*devlet memuru*” (m. 450, b. 11) “*mülki veya askeri memur*” (m. 252) ifadeleri kullanılmıştır.

²²⁰ Ancak, belirtmek gerekir ki; Anayasa Mahkemesi, bir fiilden dolayı failin bir defadan fazla cezalandırılmasına imkân tanıyan mülga 765 sayılı TCK’nın 536. maddesinin 1 ve 2. fıkralarının Anayasaya aykırı olmadığı yönünde karar vermiştir: Anayasa Mahk., 19.4.1980, E: 1980/1, K: 1980/25 (AMKD, sayı 18, sh. 137).

Yeni TCK yürürlüğe girdikten sonra da bu yanlış düzenleme “geleneğimiz”e devam edilmiştir. 27.12.2007 tarihli ve 5726 sayılı “*Tanık Koruma Kanunu*”nun 20. maddesinde “*Bu Kanunun uygulanması nedeniyle öğrendikleri bilgi ve belgeleri açıklayan, yayınlayan veya her ne şekilde olursa olsun başkalarının bu bilgi ve belgeleri edinmesini ya da erişimini kolaylaştı-*

Belli birtakım hukuki değerlerin korunmasına yönelik olarak Kanunda yer verilen suç tanımları arasında bir ahenksizlik mevcuttu. Öyle ki, bu ahenksizlik, uygulamada zaman zaman karışıklıklara sebebiyet verebilecek nitelikteydi. Örneğin *hürriyeti tahdit suçunun* çeşitli maksat ve saiklerle işlenmesi, ayrı suçlar imiş gibi düzenlemeye tabi tutulmuştu. Söz konusu suçun temel şekli, Kanunun 179. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanmıştı. İkinci fıkrada ise, *hürriyeti tahdit fiilinin* “*öç alma kastıyla veya dinî veya millî bir maksatla ... veya siyasi veya ideolojik veya sosyal görüş ayrılıklarından kaynaklanan herhangi bir amaçla*” işlenmesi, bu suçun nitelikli şekli olarak tanımlanmıştı.

Buna karşılık, *hürriyeti tahdit fiilinin* “*şehvet hissi veya evlenme maksadiyle*” işlenmesi, Kanunun başka bir yerinde ayrı bir suç olarak tanımlanmıştı (m. 429, 430).

Keza, “*para veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet almak için*” bir insanın *hürriyetinin tahdit edilmesi*, başka bir suç olarak tanımlanmıştı (m. 499, f. 1). Hatta, *hürriyeti tahdit fiilinin* “*siyasi veya sosyal maksatlarla veya resmî makamları bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için*” işlenmesi, bu madde-deki suçun nitelikli şekli olarak tanımlanmıştı (m. 499, f. 2).

II. Bütün bu olumsuzluklar, ülkemizde yeni bir ceza kanunu hazırlanması yönünde bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından yeni bir TCK için hazırlık çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmalardan en önemlisi, 1980’li yıllarda başlayıp, 2000’li yıllara kadar devam eden öntasarı hazırlıklarıdır.

1984’te başlayan bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ilk metin, 1987 Öntasarısı metnidir. Bu metinde 765 sayılı TCK’nın sistematığı sadece tersyüz edilmiş, madde metinlerinin dili “sadeleştirilmişti”. Ancak, özellikle Suç Teorisine ilişkin olarak günümüz ceza hukuku biliminde varılan sonuçlar, bu Öntasarıya yansıtılamamıştı.

Bu Öntasarı metnine yöneltilen eleştiriler üzerine Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan “İkinci Komisyon” tarafından 1989 yılında “yeni” bir metin hazırlanmıştır. Bu metin de, genel hükümler bağlamında teorik bir düşünce temeline dayalı bir değişiklik içermemekteydi. Önceki metnin bazı maddelerinde, kazüistik (vak’a temeline dayalı) düşünce ürünü olan bazı görüşlere dayalı değişiklikler yapılmıştı.

Belirtmek gerekir ki, 1989 Öntasarısının bazı hükümleri, yapılan kanun değişiklikleriyle 765 sayılı Kanuna iktibas edilmişti.

Bu konuda ilk adım, 1991 yılında 3756 sayılı Kanunla atılmıştır²²¹. Bu Kanunla, 765 sayılı TCK’ya 10/A maddesi olarak yeni bir hüküm ilave edilmiştir. Ceza

ranlar *fîl başka bir suç oluştursa bile ayrıca, Türk Ceza Kanununun 258’inci maddesi hükmüne göre cezalandırılır.*” (f. 1) hükmüne yer verilmiştir.

²²¹ 6.6.1991 tarih ve 3756 sayılı Kanun (RG: 14 Haziran 1991/20901).

hukuku ilkeleriyle bağdaşmayan ve fakat bir “reform” olarak nitelendirilen bu hüküm²²², Türk hakiminin *yabancı ceza kanununun uygulamasını* öngörmektedir²²³.

Keza, bu değişikliklerle, Kanunun “*Mal Aleyhinde Cürümler*” başlıklı Onuncu Babına “*Karşılıksız yararlanma*” başlığı altında yeni bir Fesıl eklenmişti (m. 521a, 521b). Bu Fasılda Suç Teorisi ilkeleriyle bağdaştırılamayan, kendi içinde tutarsız bazı hükümler kanunlaştırılmıştı²²⁴.

Bakanlık bünyesindeki yeni bir ceza kanunu hazırlık çalışmalarına bu metinden sonra da devam edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan metin, 1997 Öntasarısıdır. Bu Öntasarı metnine ilişkin olarak da pek çok eleştiri ileri sürülmüştü²²⁵.

Öntasarı’da ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmayan hükümlere yer verilmişti (m. 26, 27). Öntasarı, üçüncü şahsın fiilinden sorumluluğa yol açan objektif bir sorumluluk hali getirmekteydi²²⁶.

Bu metin, Bakanlar Kurulu tarafından 1998 yılında Hükümet Tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ise de, kanunlaşmamıştır.

Öntasarıya ilişkin çalışmalara devam edilmiş ve ortaya çıkan yeni metin tekrar 2000 yılında Bakanlık tarafından çoğaltılmıştır.

TCK Öntasarısı ile ilgili olarak 1984 yılından beri Adalet Bakanlığı nezdinde oluşturulan bütün Komisyonlara, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER başkanlık etmişti.

III. DÖNMEZER başkanlığındaki Komisyonlar tarafından hazırlanan bu Öntasarı, Bakanlar Kurulu tarafından 14.4.2003 tarihinde kabul edilerek Başbakanlık

²²² DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku*, cilt III, 11. bası, İstanbul, Eylül 1994, no. 2431, 2432.

²²³ Bu hükmün eleştirisi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “*Non bis in idem*” Kuralının Milletlerarası Değeri ve TCK’nın 10/A Maddesi Hükmüne İlişkin Değerlendirme, in: Yargıtay Dergisi, Temmuz 2002.

²²⁴ Bu hükümlerle ilgili eleştiri için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar*, Ankara, 2002, sh. 63 vd..

²²⁵ Eleştiriler için bkz. ÖZEK, Çetin: *1997 Türk Ceza Yasası Tasarısına İlişkin Düşünceler*, in: İstanbul ÜHFM, Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’na Armağan Sayısı, cilt LVI, yıl 1998, sayı 1-4, sh. 21 vd.; aynı yazar: *1997 Türk Ceza Yasa Tasarısı’na İlişkin Düşünceler*, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan’dan ayrı bası, İstanbul, 1999; ÖZGENÇ, İzzet: *Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi*, in: Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan 1999, sh. 70 vd.; ayrıca in: Kamu Hukuku Arşivi, yıl 2, sayı 1, Şubat 1999, sh. 5 vd.

²²⁶ 1997 Türk Ceza Yasası Öntasarısı ve İnsan Hakları Değerlendirme Raporu, İstanbul Barosu Başkanlığı İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 1998, sh. 6.

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 12.5.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.10/101-540/2092 sayılı yazısı ile Hükümet Tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir.

TCK Tasarısı ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu bünyesinde yürütülen bütün çalışmalara, talep üzerine, mensubu bulunduğum Fakültenin yönetimi tarafından görevlendirilerek, bilgisine başvurulmuş bir akademisyen olarak katıldım. **Yeni TCK'ya ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yapılan bütün çalışmaların redaksiyon görevi, tarafımdan yürütülmüştür**²²⁷.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda yapılan çalışmalar sonucunda Hükümet Tasarısında büyük ölçüde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda ortaya çıkan Tasarı, felsefesi, sistematığı, dili ve içeriği bakımından, **“Dönmezer Tasarısı”** olarak da bilinen **Hükümet Tasarısı**ndan farklı bir metin hüviyetini kazanmıştır.

Hazırlanan yeni Tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığının 3 Ağustos 2004 tarih ve Esas: 1/593, Karar: 60 sayılı Raporu ile Genel Kurul'da görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilerek kanunlaşan metin, onay için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 28 Eylül 2004 tarihinde Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanı tarafından 11 Ekim 2004 tarihinde onaylanan yeni (5237 sayılı) TCK, 12 Ekim 2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

²²⁷ Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun Türk Ceza Kanunu Tasarısına ilişkin 3.8.2004 tarih ve Esas: 1/593, Karar: 60 sayılı Raporu, TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 226.

Ş7. Yeni TCK'nın Hazırlanmasında Etkili Olan Felsefi Düşünceler ve Kanunun Özellikleri

I. Yeni TCK'nın hazırlanmasında esas alınan felsefi düşünceler, TBMM Adalet Komisyonu'nun Türk Ceza Kanunu Tasarısına ilişkin 3.8.2004 tarih ve Esas: 1/593, Karar: 60 sayılı Raporunda özet olarak ifade edilmiştir²²⁸:

“Suç siyaseti, barış esasına dayalı toplum düzeninin devamı için hukuka aykırı fiillerin hangilerinin suç olarak tanımlanması gerektiğinin belirlenmesinde izlenen yolu göstermektedir. Hukuka aykırı herhangi bir fiile suç niteliğini kazandıran koşullar, izlenen suç siyaseti ile belirlenmektedir.

Suç siyaseti ile güdülen amaca ulaşabilmek için, uyulması gereken ana ilkeler, kusur ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve hümanizm ilkesidir.

Kusur ilkesi, ceza yaptırımının, ancak işlediği fiilden dolayı kişinin kınanabilmesi durumunda uygulanabilmesini ifade eder. Bu ilke, bir yandan işlediği fiil dolayısıyla kusurlu olmayan bir kimseye ceza verilemeyeceğini ifade ettiği gibi; diğer yandan faile kusurundan daha ağır bir cezanın uygulanmasını yasaklar. Bu bakımdan, salt netice sorumluluğu, kusur ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

İyi bir suç siyaseti izlenirken göz önünde bulundurulması gereken ikinci ilke, hukuk devleti ilkesidir.

Hukuk devleti ilkesi, hukukun bireylere sağladığı güvenceyi belirtir. Bireylerin özgürlük alanına en derin müdahalelerde bulunan ceza hukukunun kötüye kullanılmasını önleyici önlemlerin yine hukuk düzeni tarafından konulması, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, belirlilik ilkesi, kıyas yasağı, geçmişe uygulama yasağı, hukuk devleti ilkesinin gerekleridir.

Devletin hukuka bağlılığının ideal bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için ceza kanunlarının içerik yönünden nasıl düzenlenmesi gerektiğini, hukuk devleti ilkesi belirler. Bu anlamda, ceza kanununun insana saygı esasına dayanması, işkence ve eziyet niteliğini gösteren uygulamaları etkin bir biçimde yasaklaması, insan onuruyla bağdaşmayan cezalar içermemesi, hâkimlerin keyfi ve duygusal biçimde hüküm vermelerine yol açabilecek kavram ve tanımlara yer vermemesi, ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında fiilin ağırlığı ve failin tehlikeliliğinin göz önünde bulundurulması, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

Hümanizm ilkesi, suç siyasetinin üçüncü ana ilkesini oluşturmaktadır. Bundan amaç, suç işleyen insanın yeniden sosyalleştirilmesi ve toplumsal sorumluluğa sahip bir birey durumuna getirilmesi hedefinin izlenmesidir.

²²⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 224 vd.

Türk Ceza Kanunun Tasarısı üzerinde Komisyonumuz tarafından yürütülen çalışmalarda, suç siyasetinin dayandığı bu temel felsefi ilkeler göz önünde bulundurulmuştur.”

Bu felsefi düşünceler, yeni TCK’nın özellikle 1 ve 3. maddeleri ile Kanun metni içinde vurgulanmıştır²²⁹.

“Ceza Kanununun amacı” başlıklı 1. maddeye göre;

“(1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.”

Bu maddenin gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir²³⁰:

“Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine derin biçimde müdahale eden yaptırımları içermektedir. Bu nedenledir ki bir ülkedeki ceza kanununa hâkim felsefe, değer ve ilkeler, o ülkedeki siyasi rejimin niteliğini gösterir. Nitekim tarihte ve günümüzde totaliter devletler, ideolojilerini benimsetmek ve rejimi ayakta tutmak için ceza kanunları yoluyla kişi hak özgürlüklerini ya geniş biçimde sınırlandırmışlar ya da ortadan kaldırmışlardır. Demokratik hukuk devletleri ise ceza kanunlarının kötüye kullanılmasını önlemek için, bu kanunların temel ilkelerine anayasalarında yer vermektedirler. Yine insanların adaletsiz ve haksız biçimde ceza ve tedbirlere maruz kılınmaması amacıyla başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşme ve belgede bireyi ceza kanunlarının keyfi uygulanmalarına karşı güvence altına alan hükümlere yer verilmiştir. Bu sözleşmelere taraf olan ülkemizin Anayasasında da aynı esaslar öngörülmüş olduğundan, ceza kanunun amacını tanımlayan maddeyle, bireyin sahip bulunduğu hukuki değerler, hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ön plâna çıkarılmıştır. Böylece kanunun özgürlükçü karakteri vurgulanmakta, bunun yanında bireyin; adalet ve güvenliğin sağlandığı bir toplumda yaşama hakkının gereği olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi, ceza kanunun temel amaçları arasında sayılmaktadır.”^{231, 232}

²²⁹ Yeni TCK’da izlenen suç siyaseti hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ARTUK, Mehmet Emin: *Ceza Kanununun Suç Siyaseti Bilimi Açısından Değerlendirilmesi*, in: *Ceza Hukuku Dergisi*, yıl 1, sayı 2, Aralık 2006, sh. 9 vd.

²³⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 404.

²³¹ Doktrinde, söz konusu madde hükmüne TCK bünyesinde yer verilmemesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulunulmuştur: ARTUK, Mehmet Emin/ÇINAR, Ali Rıza: *Yeni Bir Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Altı Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler*, in: *Türk Ceza Kanunu Re-*

Keza, Kanunun “*Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi*”²³³ başlıklı 3. maddesine göre;

“(1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Ceza kanununun uygulamasında kişiler arasında, ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden, ayırım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.”

Madde gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir²³⁴:

“Suç işlenmesiyle bozulan toplum düzeninde adaletin sağlanması için suç işleyen kimseye uygulanacak ceza hukuku yaptırımlarının haklı ve ölçülü ol-

formu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2004, sh. 69, 70; ARTUK, Mehmet Emin: *Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümlerine İlişkin Düşünceler*, in: Legal Hukuk Dergisi, yıl 3, sayı 32, Ağustos 2005, sh. 2761/2762; TOROSLU Nevzat/ERSOY, Yüksel: *Kanunlaşmaması Gereken Bir Tasarı*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2004, sh. 7; YARSUVAT, Duygun/BAYRAKTAR, Köksal ve diğerleri: *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinin TCK Tasarısı Hakkındaki Görüşleri*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2004, sh. 289; TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan: *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin TCK Tasarısı Hakkında Raporu*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2004, sh. 329; ÖZBEK, Veli Özer: *TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı (Açıklamalı-Gerekçeli-İçtihatlı)*, Cilt I, Genel Hükümler (Madde 1-75), 3. bası, Ankara 2006, sh. 174 vd.

Buna karşılık, doktrinde diğer bir görüş ise, söz konusu maddenin düzenlemesinin, uygun bir düzenleme olduğunu ileri sürmektedir (SOYASLAN, Doğan: Hukuk Merceği, Ankara Barosu Yayını, yıl 2006, sayı 6, sh. 575).

²³² Günümüzde “Ceza hukuku(na) bireyin haklarının sınırlandırılmasını engelleyen, hukuksal değerlerini güvenceye alan ve onların ihlalini engellemeyi hedefleyen bir” fonksiyon izafe edilmektedir. Dolayısıyla, “pozitif düzenlemelerin de bu paralelde yapılması” gerekmektedir (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 431). “Çağdaş anlamda özgürlükçü ceza hukuku anlayışı, ceza hukuku aracılığıyla birey özgürlüğüne hizmet eder. Toplumsal uzlaşmayı sağlar ve bireyler arasında barışı sağlayarak adil ve hümanist bir sentez anlayışı hedefler.” (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 436).

²³³ Bir hukuki ibarenin nasıl ters anlaşılmak istendiği hususunda ilginç bir örnekle karşı karşıya bulunmaktayız. Doktrinde bazı yazarlar, bu madde başlığından “adalet önünde eşitlik” gibi bir anlam çıkarmaktadırlar: HAFIZOĞULLARI, Zeki: *Türk Ceza Hukuku Ders Notları*, in: “<http://www.baskent.edu.tr/~zekih/uygulamaci/cezahukuku.doc>”, sh. 8 vd.; TOROSLU/ERSOY, sh. 8.

Hafizoğulları tarafından eleştirinin ötesine geçilerek bir buğuz halinin yansıması olarak kaleme alınan, yeni TCK'nın düzenlemelerine ilişkin olarak **son derece sığ, tutarsız ve hatta yanıltıcı bilgiler** içeren bu metin, bilahare Özen'in de katkısıyla “ders kitabı” olarak basılmıştır (HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 5. bası, Ankara, 2012). Bu kitabın Türkiye’de ceza hukuku uygulaması gerçekleştirmeye aday olan bir kısım gençler üzerinde ne tür bir etki bırakabileceği yönündeki değerlendirme, okuyucunun takdirine bırakılmıştır.

²³⁴ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 406.

ması gerekir. Çünkü ancak haklı ve suçun ağırlığıyla orantılı bir yaptırım ile suç işleyen kişinin bu fiilinden pişmanlık duyması sağlanabilir ve yeniden topluma kazandırılması söz konusu olabilir. Yine bireylerin hukuka olan güvenlerinin pekişmesi ve cezanın caydırıcılık etkisinin doğru biçimde gösterilebilmesi için de ceza hukukunun temel ilkelerinden olan orantılılık ilkesine uymak gerekir. Madde ile bu hususa ceza kanunda açıkça yer verilerek, ceza kanunun adaletçi bir karaktere sahip olduğu da vurgulanmak istenmiştir.

Geçmişte ve günümüzde, insanın ırk, din, düşünce veya cinsiyeti nedeniyle uğradığı haksız muamelelerin önlenmesi, insanlık camiasının temel uğraşlarından biridir. Ceza hukuku araçlarıyla yapılan ayrımcılık ise insana yönelik yapılan en zalimane uygulamalardan biridir. Özellikle totaliter rejimlerdeki ayrımcılığın ortaya çıkardığı felaketler insanlık tarihinde unutulamayacak acı izler bırakmıştır. İşte bu nedenlerdir ki insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelerde ve Anayasamızda ifade edilen eşitlik ilkesine yer verilerek, ceza kanunun insancıl niteliğe sahip olduğuna da işaret edilmektedir. Ceza kanunlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında bireyler arasında herhangi bir sebeple ayırım yapılmamasının ifade edilmesi, aynı zamanda hukuk devletinin özünü oluşturan insan onurunun korunmasının ceza kanununda da temel değer olarak benimsenmesi anlamına gelmektedir.”²³⁵

²³⁵ Maddenin birinci fıkrasına göre; “Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.” Bu hükümden, somut olayda verilecek cezanın işlenen suçun “ağırlığıyla orantılı” olması gerektiği sonucu doğru olarak çıkarabiliriz. Ancak, güvenlik tedbiri açısından aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bu bakımdan söz konusu hüküm sorundur. Bu husus, TBMM Adalet Komisyonunda yeni TCK’na ilişkin müzakereler sırasında tarafımızdan gündeme getirilmiş ve söz konusu fıkra metninin şu şekilde formüle edilmesi önerilmiştir.

“Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı cezaya hükmolunur. Keza, işlenen suçun ortaya çıkardığı tehlikelilik durumuna göre güvenlik tedbiri uygulanır.”

Ancak bu düşünce ve önerimiz, Komisyon tarafından dikkate alınmamıştır.

Bu nedenle doktrinde yeni TCK’nın 3. maddesinin birinci fıkrası düzenlemesine güvenlik tedbirleri bakımından haklı olarak eleştiri yöneltilmektedir. Bu eleştirilerle ilgili olarak bkz. ARTUK/ÇINAR, Türk Ceza Kanunu Reformu, sh. 71; ARTUK, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 29; CENTEL, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 53 vd; ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 9. bası, Ankara, 2006, sh. 51.

Ancak bütün bu eleştirilerde güvenlik tedbirlerinin münhasıran suç oluşturan fiili işleyen kişi ile ilgili olarak uygulanabileceği düşüncesi hakimdir (Bkz. CENTEL, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 60). Güvenlik tedbirlerinin münhasıran fail hakkında uygulanabileceği yönündeki bu yaklaşım biçiminin doğru olmadığını ifade etmek gerekir.

Doktrinde, maddenin ikinci fıkrası hükmünün de TCK bünyesinde yer alması gerektiği yönünde eleştirilerde bulunulmuştur (ARTUK/ÇINAR, Türk Ceza Kanunu Reformu, sh. 72; ARTUK, Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2005, sh. 2763; TOROSLU/ERSOY, Türk Ceza Kanunu Reformu, sh. 8.)

II. Yeni TCK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yapılan hazırlık çalışmalarında, münhasıran bir ülke ceza kanunu dikkate alınmamıştır. Başka bir deyişle, ortaya çıkan metin, **herhangi bir ülke ceza kanunundan iktibas edilmemiştir.** Ancak, bu metnin ortaya çıkarılmasında, İspanya ile Rusya Federasyonu arasındaki yelpazede yer alan devletlerin ceza kanunlarının ilgili hükümleri hep göz önünde bulundurulmuştur. Bu bakımdan, **yeni TCK**, ceza hukukuna ilişkin **Türk doktrin ve uygulamasının bir ürünü** niteliğini taşımaktadır.

Yeni TCK'da, anlaşılır bir Türkçe kullanılmıştır. Madde metinleri, son derece teknik bir dille ifade edilmiştir. Kullanılan kavramlar, farklı anlaşılmaları önleyecek biçimde ve özenle seçilmiştir²³⁶.

Maddelerin yazımında, uygulama açısından son derece kolaylık sağlayacak bir sistematik benimsenmiştir. Maddeler fıkralara, fıkralar bentlere, bentler ise alt bentlere bölünmüştür. Her fıkranın başına parantez içinde fıkra numarası konmuştur. Bentler harf sırasına göre sıralanmış ve harflerden sonra parantez kapama işaretine yer verilmiştir. Buna karşılık, alt bentler ise, sayıdan sonra nokta konmak suretiyle numaralandırılmıştır.

III. Yeni TCK'da, bireyin sahip bulunduğu hukuki değerlerle, hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, ceza kanununun amacı olarak belirlenmiştir. Böylece kanunun özgürlükçü karakteri vurgulanmıştır. Bireyin bir hukuk toplumunda yaşama hakkının gereği olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi, ceza kanunun temel amaçları arasında sayılmıştır.

Keza, bu eleştiriler kapsamında TCK'nın bünyesinde bu ikinci fıkra hükmüyle çelişen düzenlemelere yer verildiği ileri sürülmüştür (TEZCAN/ERDEM, Türk Ceza Kanunu Reformu, sh. 333; ARTUK/ÇINAR, Türk Ceza Kanunu Reformu, sh. 73; ARTUK, Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2005, sh. 2763). TCK'nın çeşitli maddelerinde suçun fail veya mağdurunun vatandaş veya yabancı olmasına göre değişik hükümlere yer verilmiş olduğu doğrudur. 12, 18, 19 ve 60. maddeler bu hususta örnek olarak gösterilebilir. Ancak, işaret etmek gerekir ki, 3. maddenin ikinci fıkrasında vatandaşlık bağı bakımından ayırım yapılamayacağı yönünde hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan söz konusu eleştiriler temelsizdir.

²³⁶ Ancak, Kanunun bazı maddelerinde kullanılan dil veya ibareler bakımından sorun bulunmadığını söylemek mümkün değildir.

Örneğin, Kanunun 6. maddesinde yer alan “*deyiminden*” ibaresi, Türkçe dilbilgisi kurallarına aykırıdır. Burada “*deyim*”, “Öztürkçe” kullanma uğruna, yanlış olarak **ibare** karşılığında kullanılmıştır. Dönmezer Tasarısından (m. 4) Kanuna aynen geçen bu yanlışlığın, “*deyiminden*” yerine “**ibaresinden**” ibaresinin konulması suretiyle düzeltilmesi için TBMM Adalet (Alt) Komisyonundaki girişimimiz sonuçsuz kalmıştır.

Keza, Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “*zaman süresi*” ibaresi, Türkçe dilbilgisi kurallarına aykırıdır. Burada aslında “**zaman zarfı**” ibaresinin kullanılmıydı. Dönmezer Tasarısında “Öztürkçe” dil kullanma uğruna, “*zaman zarfı*” ibaresi yerine yanlış olarak “*zaman süresi*” kullanılmıştır (m. 4). Kanuna aynen geçen bu yanlışlığın düzeltilmesi için TBMM Adalet (Alt) Komisyonundaki girişimimiz, “Öztürkçeleştirme” cereyanının baskın çıkması dolayısıyla sonuçsuz kalmıştır.

Anayasamıza göre, hangi fiillerin suç oluşturduğunun kanunda açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu nedenle, ancak bir kanuni tanımda belirlenen muayyen fiiller, ceza yaptırımını gerekli kılabilir. Bu düşüncelerle, yeni TCK metninde, idarenin düzenleyici işlemleriyle bir suç tanımının kapsamının belirlenemeyeceği ve ceza konulamayacağı hüküm altına alınmıştır (m. 2, f. 2).

Yine suçta ve cezada kanunilik ilkesinin doğal bir sonucu olan kıyas yasağı Kanun metninde açıkça vurgulanmıştır (m. 2, f. 3). Ancak bu hükümle ceza hukukunda genişletici yorum tümüyle yasaklanmamakta, sadece bu yorum biçiminin kıyasa yol açacak şekilde uygulanmasının önüne geçilmek istenmektedir.

Hükümet Tasarısında, “ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz” hükmüne yer verilmişti. Böylece, klasik ceza hukuku anlayışının bir sonucu olan “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” kuralının kapsamı, büyük ölçüde daraltılmış olmaktadır. Keza, yeni TCK’nın 30. maddesinin dördüncü fıkrasıyla, bu kuralın, Anayasamızda güvence altına alınan kusura dayalı ceza sorumluluğu ilkesiyle uyumunun sağlanması amaçlanmıştır.

Ceza kanunuyla, çeşitli özel suç tanımlarına yer veren diğer kanunlar arasındaki ilişki, Anayasamızda güvence altına alınan hukuk devleti, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak yeniden belirlenmiştir.

Mevzuatımızda halen yürürlükte bulunan pek çok kanunda, suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, örneğin teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konularda da Ceza kanununda benimsenen ilkelerle çelişen hükümlere yer verilmektedir. Böylece, ceza kanununda benimsenen genel kurallara aykırı uygulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanılmaktadır. Tüm bu sakıncaların önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk uygulamasında birliği sağlamak ve hukuk güvenliğini sağlamak için; diğer kanunlarda sadece özel suç tanımlarına yer verilmesi ve bu suçlarla ilgili yaptırımların belirlenmesi ile yetinilmesi gerekir. Suç ve yaptırımlarla ilgili olarak Ceza kanununda belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tanımlanan suçlar açısından da uygulanmasının temin edilmesi gerektiği düşüncesiyle, yeni TCK’da farklı bir düzenleme yapılmıştır (m. 5).

Kanunun “*Tanımlar*” maddesinde, örneğin, “*çocuk*” ibaresi, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak tanımlanmıştır. Keza, kamu görevlisi kavramının benimsenmesiyle, kimlerin “ceza kanunu uygulamasında memur” sayılacağı konusundaki yersiz ve anlamsız tartışmalara, çeşitli kanunlarda yer verilen kazüistik hükümlere son verilmesi amaçlanmıştır.

Ceza kanununun yer bakımından uygulama alanı belirlenirken, Türkiye’nin egemenlik alanı içinde işlenen suçlarla ilgili olarak milletlerarası hukuk uygulamasında non bis in idem kuralına hiçbir surette geçerlilik tanınmamıştır (m. 9). Buna karşılık, yurt dışında işlenen suçlar bakımından, bu kurala büyük ölçüde geçerlilik tanınmıştır (m. 11, 12, 13).

Yeni TCK'da, yabancı ülkede verilmiş mahkûmiyet kararına bağlı hak yoksunlukları bakımından, 765 sayılı Ceza Kanunundan farklı bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede, yabancı bir mahkeme tarafından hükmedilmiş olan cezaların doğurduğu hak yoksunlukları bakımından ülkemiz hukukunun dikkate alınması kabul edilmiştir (m. 17).

Suçluların iadesi bakımından, milletlerarası ceza hukuku alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak, ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır (m. 18)²³⁷.

Türk hâkimi, yargılamak durumunda olduğu somut olayla ilgili olarak ancak Türk kanunlarını uygulamak görev ve yetkisine sahiptir. Bu nedenle, yabancı kanunun doğrudan doğruya yurt içinde uygulanması kabul edilemez. Aksi görüş, Devletin hâkimiyet ilkesiyle bağdaşmadığı ve Anayasaya aykırı olduğu gibi, uygulamada da pek çok güçlüğü ve hatta imkansızlığa sebep olur. Çünkü, yabancı ceza kanununun uygulanması, hem fiilin suç olarak tespitinde ve cezanın tayininde yabancı kanunun ölçü olarak alınması anlamına gelmektedir. Türk hâkiminin yabancı kanunu bu şekilde uygulaması, egemenlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, böyle bir uygulamanın olanaklı olduğundan da söz edilemez. Buna karşılık, adalet ilkesi gereğince yabancı kanunun göz önünde tutulması mümkündür. Yeni TCK'da bu düşüncelerle yapılan düzenlemeyle, yurt dışında işlenen suçlar bakımından, **suçun işlendiği ülke kanununun göz önünde bulundurulması** konusunda aranacak koşullar açık bir şekilde belirlenmiştir (m. 19).

765 sayılı Ceza Kanunundan farklı olarak, yeni TCK'da, suçlar arasındaki “cürüm” ve “kabahat” ayrımı kaldırılmıştır. 765 sayılı Kanunda yer alan bazı “kabahat”ler, suç olarak metinde muhafaza edilmiştir. Belirtmek gerekir ki, bu ayrımın kaldırılmasının sonucunda, ülkemiz açısından idari yaptırımları gerektiren fiillerle ilgili olarak genel bir düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

IV. Öntasarı hazırlıklarının yansımalarıyla 765 sayılı Kanunda bilinçli taksir kavramına açıkça yer verilmesi karşısında; yeni TCK'ya ilişkin TBMM Adalet Komisyonundaki çalışmalarda, olası kast kavramının da kanun metninde tanımlanması gerektiği vurgulanarak, bunun ceza miktarının belirlenmesinde ne ölçüde dikkate alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştır (m. 21).

765 sayılı Kanunun taksire ilişkin hükümlerinde, bu konudaki teorik gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle, değişiklik yapılmıştır. Yeni TCK'nın 22. maddesinde, taksirin kast gibi haksızlığın manevi unsurunu oluşturduğu ve bu kavramların salt bir kusurluluk şekilleri olmadığı düşüncesi hâkim olmuştur. Ayrıca, yapılan düzenlemeyle, normatif bir kavram olan taksire dayalı kusurluluk durumlarında, kusurun matematiksel oranlar olarak ifadesinden vazgeçilmiştir.

²³⁷ Ancak belirtelim ki, bilahare 23.04.2016 tarihli ve 6706 sayılı **Cezâî Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu** ile TCK'nın 18. maddesi yürürlükten kaldırılmış (m. 36) ve bu madde hükümleri söz konusu Kanuna taşınmıştır (m. 10-22).

Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar bakımından, objektif sorumluluktan vazgeçilerek, kusura dayalı sorumluluk sistemi benimsenmiştir (m. 23). Kişi suç teşkil eden bir fiili işlerken, kastettiği neticeden daha ağır veya başka bir netice gerçekleşmiş olabilir. Bu gibi durumlarda netice sebebiyle ağırlaşmış suç söz konusudur. 765 sayılı Kanunda, kişi gerçekleştirmeyi kastetmediği ve hatta öngöremediği böyle neticelerden objektif olarak sorumlu tutulmaktadır. Bu tür sorumluluk, ortaçağ Kilise hukukunun kalıntısı olan “*versari in re illicita*”, yani hukuka aykırı bir durumda olan bunun bütün neticelerine katlanır anlayışının ürünü olup, çağdaş ceza hukuku bu anlayışı çoktan terk etmiştir. Çünkü kusurun aranmadığı objektif sorumluluk halleri kusursuz ceza olmaz ilkesiyle açıkça çelişmektedir. Ülkemiz ceza hukuku öğretisinde uzun süredir objektif sorumluluk hâllerinin ceza mevzuatından çıkarılması gerektiği ifade edilmektedir. Anayasada öngörülen kusur ilkesinin gereği olarak, yapılan düzenlemeye göre; meydana gelen ağır netice açısından kişinin sorumlu tutulabilmesi için, söz konusu neticeye ilişkin olarak en azından taksir dolayısıyla kusurlu bulunması gerekmektedir.

Hükümet Tasarısının Birinci Kitap, İkinci Kısım, “Hukuka Uygunluk Nedenleri” başlıklı Üçüncü Bölümü altında yer alan hükümlerin bir çoğunun hukuki niteliği doktrinde tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Doktrinde bazı görüşler ve hatta bazı ülke kanunları, örneğin zorunluluk hâlini bir hukuka uygunluk nedeni değil, kusurluluğu ortadan kaldıran (daha doğru ifadeyle, kusurluluğu etkileyen) bir neden olarak kabul etmektedir. Aynı şekilde, yetkili merciin emrini yerine getirilmesinin genellikle bir hukuka uygunluk nedeni olduğu kabul edilirken; bazı görüşler, bu durumda hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin bulunduğunu ve dolayısıyla, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olduğunu ileri sürmektedirler. Keza, doktrin ve uygulamamızda “suça etki eden neden” olarak ifade edilen haksız tahrik, esasında kusurluluğu azaltan sebep olarak değerlendirilmek gerekir. Doktrinde ileri sürülen görüşler açısından bağlayıcı olmamak için, bu Bölümde söz konusu edilen nedenlerin sonucu göz önünde bulundurulmak suretiyle bir isimlendirmeye gidilmiştir. Belirtilen nedenlerle, ilgili Bölüm başlığı “*Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler*” olarak değiştirilmiştir. Aslında arzumuz, yeni TCK’nın Birinci Kitap, İkinci Kısım, İkinci Bölüm altında yer alan maddeleri (m. 24 – 34) iki ayrı bölüm halinde düzenlemektir. Buna göre İkinci Bölümün başlığı “*Hukuka Uygunluk Nedenleri*”, bu Bölümü takip eden Üçüncü Bölümün başlığı ise, “*Kusurluluğu Etkileyen Nedenler*” şeklinde olmalıydı. Ancak, TBMM Adalet Komisyonundaki çalışmalarımız sırasında, bu bölümler altında yer alması gereken maddeler konusunda uzlaşma sağlanamadığı için, hukuki nitelikleri farklı olan bütün maddeleri, sonuçları itibarıyla ortak bir başlık altında toplayarak tek bir bölüm halinde düzenlemek zorunda kaldık.

Kusurluluğu etkileyen nedenlerle bağlantılı olarak yapılan bütün düzenlemelerde, normatif bir kavram olan kusurun iki temel unsurunu oluşturan kişinin algılama yeteneği ile davranışlarını yönlendirme yeteneğine vurgu yapılmıştır.

Yeni TCK'da, suça teşebbüs açısından “tam teşebbüs” – “eksik teşebbüs” ayırımı kaldırılmıştır (m. 35). Keza, hazırlık ve icra hareketi ayırımında, objektif ölçüye itibar edilmiştir. Gönüllü vazgeçme, bu düzenlemeye paralel olarak suça teşebbüs kapsamında yeniden düzenlenmiştir (m. 36). Buna karşılık, etkin pişmanlık, sadece belirli suçlar bakımından, ilgili suçla bağlantılı olarak cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep olarak düzenlenmiştir.

Kasten işlenen suçların işlenişine iştirak eden kişilerin sorumluluk statülerinin belirlenmesinde, faillik ve şeriklik ayırımına sadık kalınmıştır (m. 37-41). Bu ayırımda, objektif ölçütler esas alınmıştır. Buna göre, kişinin suça iştirak dolayısıyla sorumluluk statüsünün belirlenmesinde, suçun işlenişine bulunduğu katkının, gerçekleştirilen suçun icrası üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulacaktır.

İzlenen suç siyasetinin gereği olarak, kusur yeteneği olmayan çocuk veya akıl hastalarının suçun işlenmesinde araç olarak kullanılması ya da azmettirme ilişkisinde azmettirilenin çocuk olması hâllerinde cezada artırım öngörülmüştür (m. 37, f. 2; m. 38, f. 2). Bu düzenlemede, suçun işlenmesinde kullanılmakla bu kişilerin de mağdur edildiği düşüncesi etken olmuştur.

Birden fazla kişinin iştiraki bir suçun işlenmesini genellikle kolaylaştırmaktadır. Ancak, iştirake ilişkin hükümler, işlenen suça ilişkin kanuni tanımda yer alan fiillerin tamamını gerçekleştirmeyen, ya da bu tanıma uygun bir davranış gerçekleştirmeksizin suçun işlenişine iştirak eden suç ortaklarının sorumluluk statülerini belirlemektedir. Bu bakımdan, bir suçun iştirak hâlinde işlenmesi, iştirak statüleri arasında herhangi bir ayırım yapmaksızın, o suçtan dolayı kişilere verilecek cezanın artırılması nedeni olarak mütalâa edilemez. Buna rağmen, 765 sayılı Kanunda olduğu gibi, Hükümet Tasarısında, örneğin hırsızlık (m. 202, 203) ve yağma (m. 207) suçları açısından, bu suçların iştirak hâlinde işlenmesinin daha ağır cezayı gerektirdiği yönünde düzenlemeler yer almakta idi. Ancak, belirli suçlar bakımından sadece icra hareketlerinin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâl olarak kabul edilebilir. Bu düşüncelerle, yeni TCK'da, hürriyete karşı bazı suçların yanı sıra, cinsel saldırı ve yağma gibi suçlarda, icra hareketlerinin birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi, bu suçların arzettiği özellikler göz önünde bulundurularak, ilgili suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir.

Ceza hukukunun temel kurallarından birisi, “kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır” şeklinde ifade edilmektedir. Bunun istisnaları, suçların içtimai bölümünde belirlenmiştir (m. 42-44). Bu istisnalar dışında, işlenen her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir. Böylece verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır. Hükmolunan birden fazla aynı veya farklı

nitelikteki cezanın ne suretle infaz edileceği sorununun infaz kanununda düzenlenmesi gerektiği düşüncesiyle; yeni TCK’da “cezaların içtimai”na ilişkin hükümlere yer verilmemiştir.

V. Yaptırım sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. 19. yüzyıl ceza hukuku anlayışının kalıntısı olan “asli ceza” ve “fer’î ceza” ayırımı kaldırılmıştır. Suç olgusu dolayısıyla uygulanabilen yaptırımlar, ceza ve güvenlik tedbiri olarak belirlenmiştir (m. 45).

Suçlar arasındaki “cürüm” ve “kabahat” ayırımı terk edildiği için, 765 sayılı Kanunda hürriyeti bağlayıcı ceza açısından kabul edilen “hapis” ve “hafif hapis” ayırımı da kaldırılmıştır. Böylece, temel ceza olarak, hapis cezası benimsenmiştir.

Hapis cezası ile ilgili olarak kabul edilen düzenlemelerde, bir kişinin toplumdan tamamen tasfiyesini öngören bir yaptırım kabul edilmemiştir.

Somut olayda hükmedilen hapis cezasının kısa süreli olması durumunda, etkin ve ülkemiz koşulları bakımından da uygulanabilirliği olan seçenek yaptırımlar öngörülmüştür (m. 50).

Suç işlemiş olsun veya olmasın, insan kişiliğinin gelişimi, ancak serbest iradeye dayalıdır. Davranışların serbestçe belirlenebilme hürriyeti, insan kişiliğinin gelişiminin olmazsa olmaz koşulunu oluşturmaktadır. Suç işlemiş olan bir insanın dahi kişiliğini geliştirebilmesi için belirli ölçüde davranışlarını yönlendirme hürriyetine sahip olması gerekir.

Suç işleyen kişinin mahkûm olduğu cezanın infaz edilmesiyle güdülen asıl amaç kişiye gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla etkin bir uyarıda bulunmak ve kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlamaktır. Cezaların infazıyla mahkûm gelecekte sosyal sorumluluğa sahip olarak suçsuz bir yaşantı sürmeye yatkın duruma getirilmelidir. Ancak, bu amaç, bazı suçlular açısından sadece bir cezaya mahkûm olmakla da sağlanmış olabilir. Bu bakımdan, kişinin sadece belli bir cezaya mahkûm olmasıyla cezanın uyarı fonksiyonunu gerçekleşmesi ve failin bu suçtan dolayı etkin pişmanlık duyması durumunda, artık cezaevi ortamına konmaması gerekir. Kısa süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezasının infaz kurumunda çektilmesi bakımından, cezanın özel önleme fonksiyonu daima kuşku ile karşılanmıştır. Bu bakımdan, kısa süreli hapis cezasına mahkûm olan kişilerin uslandırılmasının, eğitiminin ve resosyalizasyonunun sağlanması için etkin seçenek yaptırımların belirlenmesine büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Yeni TCK’da belirlenen seçenek yaptırımlar, bu amacı gerçekleştirebilecek niteliktedir.

Yaptırım rejimine ilişkin olarak Ceza kanununda yer alması gereken hükümler açısından, bir suç dolayısıyla yapılan yargılama sonucunda karara bağlanabile-

cek hususlar, sınır ve ölçü olarak alınmıştır. Bu bakımdan, koşullu salıvermeye ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların özel infaz rejimlerine ilişkin hükümlere, yeni TCK kapsamında yer verilmemiştir.

Erteleme müessesesiyle ilgili olarak yeni TCK'da, 765 sayılı Kanundan farklı bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede erteleme, sadece hapis cezası ile ilgili olarak kabul edilmiştir. Keza erteleme, bir koşullu af olmaktan çıkarılıp, ceza infaz kurumu haline getirilmiştir (m. 51).

Ertelemede denetim süresi içerisinde hükümlü bakımından söz konusu olabilecek yükümlülükler açısından da bazı yenilikler getirilmiştir. Örneğin erteleme sadece mağdurun değil, kamunun uğradığı zararın da tamamen tazmini koşulu-na bağlanabilir hâle getirilmiştir.

Ayrıca, cezanın ertelenmesi hâlinde denetimli serbestlik tedbirinin daha etkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak için, Hükümet Tasarısındaki madde metninde bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin denetimli serbestlik süresi içinde bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine; bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına; ya da, onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, özellikle bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine karar verilebilir.

Getirilen diğer bir yenilik de, denetim süresi içinde hükümlüyle ilgili olarak uzman bir kişinin görevlendirilmesidir. Hükümlüye rehberlik edecek bu uzman kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.

Bu düzenleme, Adalet Bakanlığı bünyesinde denetimli serbestlik büroları olarak yeni bir teşkilatlanmayı gerekli kılmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 3.7.2005 tarihli ve 5402 sayılı **Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu** çıkarılmıştır²³⁸.

Suçlar arasındaki “cürüm” ve “kabahat” ayırımının kaldırılması, para cezası bakımından da “ağır para cezası” ve “hafif para cezası” ayırımının terk edilmesi sonucunu doğurmuştur. Ancak, bunun sebebiyet verebileceği, bir suç karşılığında öngörülen ve mahkeme tarafından hükmedilen para cezası ile idari yaptırım olarak uygulanan para cezası arasındaki kavram karışıklığını önlemek için, ceza hukuku yaptırımı niteliğindeki para cezasının adı, *adli para cezası* olarak belir-

²³⁸ RG: 20 Temmuz 2005/25881.

lenmiştir. Adli para cezası bakımından gün para cezası sistemi benimsenmiştir (m. 52). Bu sistemde adli para cezası, kural olarak hapis cezasına seçenек yaptırım şeklinde kabul edilmiştir. Ancak, özellikle ekonomik çıkar amaçlı suçlarda suçun işlenmesiyle bir çıkar elde edildiği kesin olarak öngörölmekle birlikte, bunun miktarının belirlenemediği durumlara özgü olarak hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da öngörölmüştür.

VI. Yeni TCK’da, güvenlik tedbirleri, Hükümet Tasarısından farklı olarak, son derece sade bir şekilde düzenlemeye tabi tutulmuştur. Hükümet Tasarısında, bir taraftan “fer’i ceza”lara, diğer taraftan da güvenlik tedbirlerine yer verilmişti. Ancak, öngörölen “fer’i ceza”larla güvenlik tedbirleri arasında kabul edilebilir somut bir ölçüt belirlenmemiştir. Bu şekildeki düzenleme, 765 sayılı Kanundaki erteleme hükümlerinin ortaya çıkardığı sorunların devam etmesini sonuçlayacak nitelikte göröldüğü için; erteleme kurumunun hukuki yapısında değişiklik yapıldığı gibi, “fer’i ceza” kavramı terk edilmiş ve güvenlik tedbirleri bir sistematik çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen kişi, toplumda belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Ancak, bu yoksunluk, kural olarak, mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Cezanın infazı, kişinin işlediği suçtan dolayı etkin pişmanlık duymasını, yeniden topluma kazanılmasını gerektirdiğine göre; cezasını çekmiş olan kişi artık toplumla barışmış, suç işlemekle kaybettiği toplumsal güveni geri kazanmış demektir. Bu bakımdan, benimsenen yaptırım sisteminde, belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkûmiyetin sonucu olarak ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu söz konusu değildir (m. 53).

Hükümet Tasarısından farklı olarak, bir güvenlik tedbiri niteliğinde kabul edilen müsadere, eşya müsadere ve kazanç müsadere şeklinde bir ayırıma tabi tutularak düzenlenmiştir (m. 54, 55). Yeni TCK’da kabul edilen bu düzenlemede, Hukuk Toplumunda suçun bir kazanç elde etme yolu olarak görölmemesi ve suç işlemek suretiyle kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi gerektiği yönündeki düşünce hâkim olmuştur.

Müsadereye ilişkin genel ve kuşatıcı bir düzenleme yapıldığı için, rüşvet gibi çeşitli suç tanımlarıyla bağlantılı olarak müsadereyi özel olarak düzenleyen hükümlere ayrıca yer verilmemiştir.

Hükümet Tasarısının Birinci Kitabının Beşinci Kısımında “Çocuk ve Küçüklere İlişkin Hükümler”e ve bu düzenlemeler kapsamında, “çocuk” ve “küçük” ayırımına yer verilmişti. Keza, bu düzenlemelerde, örneğin hapis cezasından ayrı olarak “çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezası” öngörölmüştü. Bu Kısımda, Genel Hükümler Kitabında yer alan bazı düzenlemelerle ilgili olarak, örneğin dava veya ceza zamanaşımı, erteleme ve koşullu salıverme bakımından çocuklar ve “küçükler”e özgü ayrı hükümlere yer verilmişti.

Kanunlaşan düzenlemelerde, Hükümet Tasarısının benimsediği bu sistemden vazgeçilmiştir. Bununla bağlantılı olarak, suç yoluna sürüklenmiş çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin nelerden ibaret olduğu ve bunların ne suretle uygulanacağı hususlarında çocuklarla ilgili kanun içeriğinde düzenleme yapılması uygun görülmüştür.

Yeni TCK'da, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişiler hakkında öngörülen koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirinin bu amaca özgü donanımlı sağlık kuruluşlarında uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır. Keza, bu güvenlik tedbiri açısından belli bir süre öngörülmüş değildir. Benimsenen sistemde, koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbiri uygulanmasına, akıl hastasının iyileşmesine kadar değil, toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına kadar devam edilecektir. Söz konusu tedavi amaçlı güvenlik tedbiri, suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişiler açısından da öngörülmüştür (m. 57).

Tekerrür, cezanın artırılmasını gerektiren bir neden olarak kabul edilmiş değildir. Tekerrür halinde suç işleyen kişi, itiyadî suçlu, suçu meslek edinen kişi ve örgüt mensubu suçlu gibi, toplum açısından daha fazla tehlike ifade etmektedir. Bu itibarla, mükerirlerin yanı sıra, itiyadî suçlu, suçu meslek edinen kişi ve örgüt mensubu suçlu kişiler açısından, bunlara özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri öngörülmüştür (m. 58).

Ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralı bağlamında, özel hukuk tüzel kişileri hakkında ceza yaptırımının uygulanamayacağı; buna karşılık, güvenlik tedbiri niteliğinde yaptırımlara hükmedilebileceği kabul edilmiştir (m. 20, f. 2). Özel hukuk tüzel kişileri hakkında ceza yaptırımının uygulanması uygun görülmemekle beraber, bu tüzel kişiliklerin faaliyeti çerçevesinde, bunların yararına olarak suç işlenmekte olduğu vakıası karşısında, bunlarla ilgili olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır (m. 60).

VII. 765 sayılı Kanunda olduğu gibi, Hükümet Tasarısında bir suça ilişkin cezanın belirlenmesinde aynı neden birkaç defa dikkate alınabilecek şekilde düzenleme yapılmıştı. Örneğin temel cezanın belirlenmesinde, başka nedenlerin yanı sıra, “failin geçmişi, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri, kişisel ve sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları gibi hususlar” da dikkate alınacaktı (m. 79). Ancak, aynı nedenlerin, “Takdire bağlı hafifletici nedenler” başlıklı 33. madde hükmü çerçevesinde cezanın bireyselleştirilmesi bağlamında da dikkate alınması gerekmekteydi. Halbuki, kişi hakkında işlediği suç nedeniyle ceza belirlenirken bir neden ancak bir defa dikkate alınabilir.

Yeni TCK'da, cezanın belirlenmesine ve bireyselleştirilmesine ilişkin hükümler, bu düşünceler çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir (m. 61). Bu düzenlemede cezanın belirlenmesinde izlenmesi gereken yöntem, açık ve denetime imkan

tanıyacak bir biçimde ortaya konulmuştur. Bu düzenlemeye göre, somut olayda ilgili suç tanımında belirlenen cezanın alt ve üst sınırı arasında ceza tayin edilirken, cezanın belirlenmesine ilişkin madde hükmünde gösterilen ölçütler dikkate alınacaktır. Cezanın belirlenmesine ve bireyselleştirilmesine ilişkin hükümlerle, soyut gerekçeler göstererek cezanın alt veya üst sınırdan belirlenmesi şeklindeki yanlış uygulamanın önüne geçilmek amaçlanmıştır.

VIII. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin asıl amacı, suç mağdurunun mağduriyetini gidermek değildir. Ancak, izlenen ceza siyasetiyle, suç mağdurunun uğradığı zararların karşılanması mümkün kılınabilmektedir. Bu bakımdan, mağdurun korunması amacıyla, örneğin kısa süreli hapis cezası açısından mağdurun uğradığı zararların karşılanması seçenek yaptırımına yer verildiği gibi; hapis cezasının ertelenebilmesi, mağdurun uğradığı zararların karşılanması koşuluna bağlanabilmektedir.

Çeşitli suçlarla bağlantılı olarak kabul edilen etkin pişmanlık hükümleriyle de, suçun işlenmesiyle ortaya çıkan mağduriyetlerin etkilerinin veya ekonomik zararların mümkün olduğunca azaltılması amaçlanmıştır. Örneğin, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında, izlenen suç siyasetinin gereği olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma fiili suç olarak tanımlanmamıştır²³⁹. Çünkü, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmakla kişiler aslında kendi sağlıklarını kaybetmektedirler. Bu nedenle, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişiler, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulacaklardır. Ancak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın almak veya başka surette elde etmek, suç olma özelliğini muhafaza etmektedir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanan kişinin, bunu kimlerden ve ne suretle elde ettiği yönünde bilgi vermesi ya da hakkında uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması durumunda, bu nedenle cezalandırılmayacaktır (m. 191, 192).

²³⁹ Ancak, belirtmek gerekir ki, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla TCK'nın 191. maddesinde yapılan değişiklikle, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak fiili de suç olarak tanımlanmıştır.

“Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.” (2918 s. K, m. 48, f. 11).

Önemle belirtmemiz gerekir ki, bu hükümlere “göre geri alınan sürücü belgesinin iade edilebilmesi için; ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla (2018 s.) **Kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması**; uyuşturucu veya uyarıcı madde alması nedeniyle sürücü belgesi geri alınanların ayrıca sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi **şarttır.**” (2018 s. K, m. 48, f. 13).

Fuhşa sürüklenen kişinin tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulması da, suç mağdurunun korunması amacına yönelik bir güvenlik tedbiri olarak düşünülmüştür (m. 227, f. 8).

Yeni TCK'da çocukların korunması amacına yönelik yeni suç tanımlarına yer verilmiştir. Örneğin kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı suçlar bağlamında, çocukların cinsel istismarı, ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir (m. 103). Aynı şekilde çocuklara sağlık için tehlike oluşturabilecek maddelerin verilmesi, suç olarak tanımlanmıştır (m. 193). İçerik bakımından müstehcen nitelikte olan ürünlerden çocukların etkin bir şekilde korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır (m. 226). Ayrıca, toplumsal geleceğimiz açısından son derece tehlikeli bir mahiyet taşıması itibarıyla, çocukların fuhşa sürüklenmesi fiilleri, etkili ceza yaptırımına altına alınmıştır (m. 227).

IX. Hükümet Tasarısında, bazı suçlar bağlamında, bunların Tasarı sistematigindeki yeri itibarıyla, Tasarının Genel Gereğesinde belirtilenin aksine, bireyin korunması ikinci planda kalmıştı. Örneğin, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı fiiller, Hükümet Tasarısının İkinci Kitabının “Topluma Karşı Suçlar” başlığını taşıyan İkinci Kısımın Altıncı Bölümü altında düzenlenmişti. Buna karşılık, yeni TCK'da, bu suçlar, İkinci Kitabın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Kısımının Sekizinci Bölümünde, içerik ve sistematik bakımından yeniden tanımlanmışlardır (m. 102 vd.). Bu yeni düzenlemede, kişinin vücut dokunulmazlığı ve özellikle cinsel dokunulmazlığı daha etkin bir şekilde koruma altına alınmıştır.

İşkencenin gizli bir himaye görmesini önlemek ve işkenceyi etkin bir şekilde önleyebilmek amacıyla, işkence suçunun ihmalî davranışla işlenmesi hâline ilişkin olarak, yeni TCK'ya özel bir hüküm konulmuştur. İşkence fiilleri, bunu önlemekle yükümlü olan kamu görevlileri tarafından genellikle müsamaha ile karşılanmakta ve hatta, sarîh veya zımni bir şekilde teşvik dahi edilebilmektedir. Bu durumlarda, işkenceyi gerçekleştiren görevlileri cezalandırma imkanı bulunsa bile, işkence yapma hususunda sarîh veya zımni bir şekilde teşvikte bulunan amir konumundaki kamu görevlileri, genellikle cezasız kalmaktadır. Bu kişilerin cezasız kalmamasını temin amacıyla Kanuna hüküm konulmuştur (m. 94, f. 5).

Ayrıca, işkencenin cezalandırılabilmesi için, bunun mutlaka Türkiye'de gerçekleşmesi, bir Türk vatandaşı tarafından veya bir Türk vatandaşına karşı yapılması da gerekmemektedir. Yeni TCK'ya göre, işkencenin kim tarafından, kime karşı ve nerede yapıldığına bakılmaksızın, failleri Türkiye'de ve Türk kanunlarına istinaden cezalandırılabilecektir (m. 13, f. 1, bent c).

X. Hükümet Tasarısının Özel Hükümler Kitabındaki bir çok hüküm, sistematik bakımdan uygun olmayan yerlerde düzenlenmiş olması dolayısıyla; yeni TCK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki hazırlık çalışmaları kapsamında

Bölüm sistematiklerinin yeniden belirlenmesi sırasında, bu hükümlerden bir kısmı bulundukları yerden başka Bölüme aktarılmıştır.

Örneğin, hakaret suçu, 765 sayılı Kanunun etkisiyle, Hükümet Tasarısında İkinci Kitap, Birinci Kısım, Sekizinci Bölüm altında düzenlenmiş iken; “memura görevinden dolayı hakaret” suçu, İkinci Kitabın “Millete, Devlete ve Kamusal Barışa Karşı Suçlar” başlıklı Üçüncü Kısımın Altıncı Bölümünde düzenlenmişti. Farklı kısım ve bölümlerde düzenlenen bu hükümler, yeni TCK’da birleştirilerek, uygulamada çıkan bir çok sorunu giderebilecek bir şekilde aynı bölüm altında düzenlenmişlerdir (m. 125 vd.).

765 sayılı Kanunun yansıması olarak Hükümet Tasarısında yer alan pek çok hüküm, aslında kazüistik bir mahiyet taşıdığı için, metinden çıkarılmış veya birleştirilerek tek hüküm hâline getirilmiştir.

Örneğin, rüşvet suçuna ilişkin olarak Hükümet Tasarısının 403, 404, 405 ve 406. maddeleri hükümleri birleştirilerek; yeni TCK’da Suç Teorisinin verilerine uygun olarak ve uygulamayı kolaylaştıracak surette tek bir madde altında düzenlenmiştir (m. 252). Tasarının kazüistik bir mahiyet arzeden 419, 420, 421, 422 ve 423. maddeleri hükümleri birleştirilerek, tek bir madde altında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçu olarak düzenlenmiştir (m. 265).

Aynı şekilde, Tasarıda yer alan “Genel olarak görevi kötüye kullanma” başlıklı 488, “Görevi ihmal” başlıklı 491 ve “Keyfi muamele” suçunun tanımlandığı 480. madde hükümleri birleştirilerek; yeni TCK’da, genel mahiyette ve icraî veya ihmalî davranışla işlenebilen görevi kötüye kullanma suçu olarak tek madde altında düzenlenmiştir (m. 257).

XI. Hükümet Tasarısına 765 sayılı Kanundan aktarılan pek çok hüküm, Suç Teorisinin verileriyle bağdaşmadığı için, yeni TCK’ya alınmamıştır. Örneğin, Suç Teorisine ilişkin pek çok sorunu hareketin “nedensellik değeri”ni göz önünde bulundurarak açıklamaya çalışan 19. yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir yansıması olarak Tasarı metnine konulmuş olan “Bilinmeyen veya beklenilmeyen hâller ve nedenler” başlıklı 137. madde, metinden çıkarılmıştır. Keza, iştirake ilişkin genel nitelikteki hükümler karşısında, “Failin bilinmemesi” başlıklı 232 ve “Kavga” başlıklı 233. maddeler, gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır.

XII. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışmalarda, Hükümet Tasarısının ihale yolsuzluklarıyla mücadele bakımından içerdiği hükümleri, 765 sayılı Kanundaki düzenlemeler gibi, yetersiz bulunarak; bu husustaki suç tanımları yeniden düzenlenmiştir. Bu bağlamda, yeni TCK’da, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma olarak iki ayrı suç tanımına yer verilmiştir. Söz konusu suçların hangi fiil ve davranışlarla oluşacağı, ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, bu suçların uygulama alanı, kamu ihale mevzuatına tabi olsun veya olmasın, nitelik

bakımından kamusal faaliyette bulunan bütün kurum ve kuruluşların mal veya hizmet alım, satım ve kiralama işlemlerini kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur (m. 235, 236).

Yine, yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele için izlenen suç siyasetinin gereği olarak; yeni TCK'da, kişinin haklı bir işinin gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat temin etmesi, rüşvet verme olarak nitelendirilmemiştir. Buna karşılık, menfaat sağlayan kamu görevlisinin fiili, somut olayın koşullarına göre, icbar suretiyle irtikap veya genel nitelikte görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacaktır. Böylece, haklı bir işinin gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat sağlayan kişi mağdur olarak telakki edileceği için, bu fiillerin açığa çıkması büyük ölçüde sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, rüşvet suçunun uygulama alanı, nitelik bakımından kamusal faaliyette bulunan bütün kurum ve kuruluşların görevlilerini kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur (m. 252, f. 4).

XIII. Hükümet Tasarısının İkinci Kitap, İkinci Kısımındaki “Genel Tehlike Yaratıcı Suçlar” başlıklı Birinci Bölüm altında yer alan suç tanımlarında, oluşturulan tehlikenin sebebiyet verdiği zararlı ağır neticeler açısından da hükümlere yer verilmişti. Bu durum, 765 sayılı Kanunda olduğu gibi, söz konusu ağır neticelerden sorumluluk ile zarar suçlarından sorumluluk arasında bir karışıklığa neden olmaktadır. Örneğin yangın çıkarmak, Hükümet Tasarısının 234. maddesinde bir tehlike suçu olarak tanımlanmıştı. 240. maddede ise, yangının ölüme sebebiyet vermesi hâli ile ilgili olarak “on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası” öngörülmüştü. Tasarının sisteminde, meydana gelen bu ağır neticeden sorumluluk için failin kusurlu olması şart olmadığı gibi, bu netice açısından kast veya taksirle hareket etmesi ve hatta, ölen kişi sayısı önemli değildi. Buna karşılık, Tasarının 136. maddesinde, kasten öldürme suçunun örneğin yangın çıkararak işlenmesi hâli ile ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmüştü.

Yeni TCK'da ise, belirli tehlikelere neden olmak başlı başına bir suç olarak tanımlandıktan sonra, bu tehlike sonucunda bir zararın meydana gelmesi hâliyle ilgili olarak ayrıca özel hükümlere yer verilmemiştir. Bu durumda, meydana gelen netice açısından, kusura dayalı sorumluluk sisteminin benimsendiği netice sebebiyle ağırlaştırılmış suça ilişkin hükümler çerçevesinde sorumluluk yoluna gidilmelidir. Ayrıca, bu gibi olaylarda, farklı neviden fikrî ictima (m. 44) hükümleri uygulanarak, fail hakkında tek bir suçtan dolayı cezaya hükmedilmek gerekecektir.

XIV. Hükümet Tasarısına 765 sayılı Kanundan iktibas edilen kamu güvenine karşı suçlara ilişkin hükümlerle ilgili olarak; yeni TCK'da gerek içerik gerek sistematik bakımdan önemli değişiklikler yapılmıştır. Özellikle belgede sahtecilik suçuyla bağlantılı olarak Tasarıda yer verilen “bu fiillerden dolayı genel veya özel bir zarar meydana geldiğinde” (m. 279) veya “bu fiilden dolayı genel

veya özel bir zarar meydana gelebildiğinde” (m. 284) gibi ifadelerle, yeni TCK’da yer verilmemiştir. Zira, sahtecilik olgusu gerçekleştikten sonra, bir “genel veya özel zarar”ın meydana gelmesini veya gelmesi ihtimalini aramaya artık gerek yoktur. Aslında 765 sayılı Kanundaki bu hükümler, sahtecilik suçundan dolayı sorumluluktan kurtulmak için kötüye kullanılmaya müsait bir durum oluşturmaktaydı. Keza, sahtecilik olgusu gerçekleştikten sonra, 765 sayılı Kanunun uygulamasında ayrıca bunun “iğfal kabiliyetini haiz” veya “aldatma yeteneğine sahip” olup olmadığını araştırmak da, sahtecilik suçundan dolayı sorumluluktan kurtulmak için bir çıkış yolu olarak görülmekteydi. Aldatıcılık özelliği, sahteciliğin özünde var olan bir husustur. Aksi takdirde, sahtecilikten söz etmek mümkün değildir.

Resmi belgede sahtecilik suçuyla bağlantılı olarak belgenin asıl, özet veya suret olması bakımından veya bu belgeler arasında, “kimlik belgesi”, “şahadetname”, “beyanname”, “zabitanın teftiş ve kontrolüne tabi defter”, “iyi hâl veya yoksulluk belgesi” ya da sağlık raporu olup olmamasına göre ayırım yapılması, toplumda hukuk güvenliğini sarsan keyfî uygulamalara imkan sağlayan bir durum olarak görüldüğü için; bütün bu ayrımlar, yeni TCK’da terkedilmiştir (m. 204 vd.).

XV. 765 sayılı Kanunda veya Hükümet Tasarısında bulunmayan yeni suç tanımlarına, yeni TCK’da yer verilmiştir.

Örneğin, insan üzerinde deney fiilleri ilk defa mevzuatımızda suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımlaması yapılırken, ülkemizde bu konuda kapsamlı bir kanuni düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, insan üzerinde bilimsel deney yapılabilmesinin ve tedavi amaçlı denemelerde bulunulabilmesinin şartları ayrıca belirlenmiştir (m. 90).

Çevrenin kirlenmesi fiilleri, hâlen yürürlükte olan 2872 sayılı Çevre Kanununa göre sadece idari yaptırımı gerektirmektedir. Halbuki çağdaş ceza kanunlarında, ekolojik dengenin bozulmasına neden olması ve çevrede kalıcı etkiler doğurması bakımından bu fiillerin suç olarak tanımlanması yoluna gidilmiştir. Yakın tarihlerde ülkemizde yaşanan kimyasal veya radyoaktif madde atık ve atıklarıyla dolu varillerin yurt dışından gelen gemilerle sahillerimize bırakılması ve hatta, bu tür maddelerle yüklü gemilerin karasularımızda kendi hâline terk edilmesi olayları, toplum olarak çevre kirliliğine karşı duyarlılığımızın artmasına neden olmuştur. Bu duyarlılığın sonucu olarak, çevrenin kasten veya taksirle kirlenmesi fiilleri, yeni TCK’da suç olarak tanımlanmıştır (m. 181, 182). Hatta, ceza kanununun yer bakımından uygulama alanına ilişkin hükümlere göre; çevrenin kasten kirlenmesi suçunun kim tarafından ve nerede işlendiğine bakılmaksızın, fiilleri Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere Türkiye’de yargılanabilecektir (m. 13, f. 1 bent d). Bu düzenlemelerin yapılmasında, çevre kirliliğine neden olan fiillerin Türkiye’nin egemenlik alanı dışında işlenmesine rağmen, hava sirkülasyonları veya denizlerdeki akıntılarla kirliliğin ülkemize de sirayet etmesi ve özellikle, Türki-

ye'ye komşu ülkelerdeki eskimiş teknolojilerle çalışan ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik yeterli teknik donanıma sahip bulunmayan atom enerji santrallerinin halen faaliyette bulunması, büyük ölçüde etkili olmuştur.

Ülkemizdeki plansız şehirleşmenin ve kamu arazilerinin işgalinin önüne geçebilmek amacıyla, “yapı ruhsatı” olmaksızın veya ruhsata aykırı olarak inşaat faaliyetinde bulunulması, suç olarak tanımlanmıştır (m. 184). Yine bu bağlamda Kanunda, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişiler açısından bir etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir (m. 184, f. 5). Buna göre, kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar plânına ve ruhsatına uygun hâle getirmesi hâlinde, hakkında bu suç nedeniyle kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olduğu ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. Bu hükümle amaçlanan, imar plânına veya ruhsata aykırılıkların bir an önce giderilmesi için, kişinin harekete geçmesini sağlamaktır. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılmış yapıların yıkılması yerel yönetimler açısından hep sorun olmuştur. Bu nedenle, burada kabul edilen etkin pişmanlık hükmü ile ilgili olarak zaman bakımından bir sınırlama getirilmemiştir. Buna göre, kişi, yaptığı veya yaptırdığı bina ile ilgili olarak imar plânına veya ruhsata aykırılıkları, bu madde hükmüne istinaden cezaya mahkum olduktan sonra gidermesi hâlinde dahi, etkin pişmanlıktan yararlanabilecektir.

XVI. Yeni TCK'da, diğer kanunlarda düzenlenen çeşitli suçlar, uygulamada karşılaşılan sorunları giderebilecek şekilde ve Suç Teorisinin verilerine uygun olarak yeniden tanımlanarak Tasarı metnine dahil edilmiştir.

Halen yürürlükte bulunan Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda organ ve doku ticareti açısından öngörülen ceza hükümlerinin yetersiz olması karşısında, bu konuda daha etkin bir ceza hukuku koruması sağlamak amacıyla, TCK'ya yeni hükümler konulmuştur (m. 91-93).

Keza, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması amacıyla yönelik fiiller de yeni TCK kapsamında bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır (m. 282). Belirtmelidir ki, halen yürürlükte bulunan 13.11.1996 tarihli ve 4628 sayılı “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair” Kanunun²⁴⁰ “karapara aklama” suçuna ilişkin hükümleri, Suç Teorisinin verilerine ve genel olarak suç tanımına ilişkin kanun tekniğine uygun değildir. Ayrıca, “karapara”nın ancak sayılı birtakım suçların işlenmesi suretiyle elde edilen ekonomik değerlere inhisar ettirilmesi, kazüistik düzenlemelere özgü sakıncaları taşımaktadır. Kanunda yer verilen yeni suç tanımı ile, 4208 sayılı Kanundaki “karapara aklama” suçuna ilişkin aksaklıkların düzeltilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca belirtmelidir ki, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçunun dışında yeni

²⁴⁰ RG: 19 Kasım 1996/22822.

TCK’da yer verilen başka hükümler de, “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair” Kanunla güdülen amaçları gerçekleştirmeye elverişli bir şekilde düzenlenmiştir. Kazanç müsaderesine ilişkin madde hükümleri (m. 55), bu konuda örnek olarak gösterilebilir.

XVII. 765 sayılı Kanunda olduğu gibi, Hükûmet Tasarısının İkinci Kitap, İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm başlığı “Kamu Düzenine Karşı Suçlar” olarak belirlenmiştir. Yeni TCK’da Bölüm başlığı “Kamu Barışına Karşı Suçlar” olarak değiştirilmiştir. Bu Bölümde tanımlanan suçların büyük bir çoğunluğu somut tehlike suçu olarak tanımlanmıştır (m. 213 vd.). Bu itibarla, ilgili suç tanımlarında belirtilen fiillerin işlenmesi, cezalandırılabilirlik için yalnız başına yeterli değildir. Bunun için, gerçekleştirilen fiilin ayrıca somut bir tehlikenin oluşumuna neden olması gerekir. Somut tehlike suçları bağlamında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, ortaya çıkan tehlikenin gerçekleştirilen fiilin eseri olmasıdır. Başka bir deyişle, oluşan somut tehlike ile gerçekleşen fiil arasında illiyet bağının bulunması gerekir.

Söz konusu suçların somut tehlike suçu olarak tanımlanması, düşünceyi açıklama özgürlüğünün güvencelerinden birini oluşturmaktadır.

Bu Bölümde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu yeniden tanımlanmıştır (m. 220). Cezalandırılabilirlik için, oluşturulan örgütün işlenmesi amaçlanan suçlar bakımından elverişli bir yapıya sahip olması gerekir. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, örgütün gerek hiyerarşik yapısı, gerek sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekir. Ancak örgütün varlığı için asgari üye sayısı üç olarak belirlenmiştir.

Örgüt kavramına ilişkin olarak bu Bölümde yer alan hükümler, bütün suçlar açısından geçerlidir. Bu bakımdan, söz konusu hükümler, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” ile “Anayasal Düzen ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bağlamında tanımlanan “Silahlı örgüt” suçu açısından da geçerlidir. Ancak, ilgili düzenlemelerde “Silahlı örgüt” suçu açısından ek unsurlara yer verilmiştir (m. 314).

Ayrıca işaret edilmelidir ki, Devletimizin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla oluşturulmuş örgütlerin yabancı devlet yetkilileri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi, Türkiye’ye karşı hasmane hareket olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır (m. 304).

XVIII. Yeni TCK’nın “Adliye Karşı Suçlar” başlıklı Bölümü altında düzenlenen suç tanımlarında, 765 sayılı Kanun ve Hükûmet Tasarısına nazaran önemli ölçüde değişiklikler yapılmıştır.

Günlük hayatta, bir suçla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve kovuşturma sürecinde, adil yargılamayı etkilemeye yönelik beyanlarda bulunulması şeklinde olaylara tanık olunmaktadır. Yeni TCK’ya konan hükümlerle (m. 288), özellikle dış kaynaklı bu etkileme girişimlerinin önüne geçilmek amaçlanmıştır.

Keza, bir suçla ilgili olarak başlatılan soruşturma işlemleri ile bağlantılı olarak basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde, suç şüphesi altında olan veya olmayan kişilerin suçlu olarak damgalanmalarını sağlayacak şekilde görüntülere yer verilmektedir. Kişiler açısından telafisi imkanı olmayan olumsuz sonuçlar ortaya çıkaran bu fiiller, yeni TCK'da suç olarak tanımlanmıştır.

Aynı şekilde, soruşturma evresindeki işlemlerin gizliliği kural olmakla birlikte, belli olaylarla ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında, dosya içeriğini oluşturan ve gizli tutulması gereken bilgi veya belgeler, basın ve yayın organlarında tefrika şeklinde yayınlanabilmekteydi. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için, gizlilik kuralını ihlâl eden davranışlar, yeni TCK'da artık suç olarak tanımlanmıştır (m. 285, 286).

Belli bir suçtan dolayı hakkında tutuklama veya hükümlülük kararı verilmiş olan kişilerin, yakalanmadan serbestçe dolaştığına tanık olunabilmektedir. Yeni TCK'ya, kişilerdeki hukuk güvenliğini sarsıcı bir etki doğuran bu davranışların önüne geçmeye yönelik hükümler konulmuştur (m. 284).

Hukuk Toplumunun bireylerinin doğruyu söylemesi esastır. Bu nedenle, söylenen sözün doğruluğuna güvenmek gerekir. Ancak, toplumumuzda belli ilişkiler bağlamında yalan söylemek ve yalan tanıklık yapmak yönündeki davranışlara bir ölçüde müsamaha ile bakılabilmektedir. 765 sayılı Kanunun yalan tanıklık suçuyla ilgili olarak öngördüğü yaptırımların yetersizliği de, bu müsamahayı pekiştirici bir etki doğurmuştur. Bu durum, toplumsal ilişkilerde söylenen sözler bakımından kişilerin birbirlerine güvensizlik duymalarına neden olmaktadır. Bu olumsuz durumun önüne geçebilmek ve tanıklık müessesesine etkinlik kazandırabilmek amacıyla; yeni TCK'da yalan tanıklık suçu ile ilgili olarak, 765 sayılı Kanuna ve Hükümet Tasarısına nazaran önemli değişiklikler getiren yeni hükümlere yer verilmiştir (m. 272-274).

Hızlı işleyen ve adil bir kararla sonuçlanan bir ceza muhakemesi süreci için, suç delillerinin korunması ve bozulmadan elde edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, Hükümet Tasarısında yapılan değişikliklerle, suç delillerinin yok edilmesi, gizlenmesi ve değiştirilmesi, suçluyu kayırma ve suçlu bildirmeme suçları yeniden düzenlenmiştir (m. 278, 279, 280, 281, 283).

XIX. Yeni TCK'da yer alan, 765 sayılı Kanuna ve Hükümet Tasarısına nazaran gerçekleştirdiği bütün bu iyileştirici düzenlemelere rağmen; bazı hükümler bağlamında arzulanan bu netice gerçekleştirilememiştir. Özellikle düşünce hürriyeti ile ilgili suç tanımlarında, 765 sayılı Kanuna ve Hükümet Tasarısına nazaran iyileştirici bazı değişiklikler yapılmış ise de; bu değişikliklerle, Hukuk Toplumu için özlenen hedefe ulaşılamamıştır.

Örneğin yeni TCK'nın, 765 sayılı Kanunun 159. maddesine karşılık gelen "Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" başlıklı

301. maddesinde geçen “Türklük” ve “Cumhuriyet” kavramları soyut kavramlar olduğu için; bunların yerine, içerikleri somut olarak belirlenebildiği için, *Türk Milleti* ve *Türkiye Cumhuriyeti Devleti* kavramlarının kullanılması önerilmiştir. “Türklük” kavramı, daha çok ırki bir bağ çağrıştırmaktadır. Bu tür kavramların Kanun metninde kullanılmasının, Türk Milletini oluşturan unsurlar arasındaki etnik ayrımları körükleyen bir etki doğurabileceği endişesini taşımaktayız.

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda, bu düşüncelerimiz tasvip edilmekle birlikte, duygusal bazı nedenlerle, bu ifadelerin Kanun metninde muhafaza edilmesi yönünde irade oluşmuştur²⁴¹.

Keza, inanç, düşünce ve kanaatleri açıklama hürriyetini kısıtlayıcı mahiyette bulduğumuz, “Temel millî yararlar karşı hareket” başlıklı 305. madde kapsamında Hükümet Tasarısına nazaran yapılan iyileştirici değişiklikler de, yeterli değildir.

Aynı şekilde, esasında bir haksızlık oluşturmeyen ve sadece İdarenin denetim fonksiyonunu güçleştirmesi bakımından idari yaptırım uygulanmasını gerektirebilecek nitelikte olan davranışların suç olarak tanımlandığı “Kanuna aykırı eğitim kurumu” başlıklı 263. madde hükmüne Kanun metninde yer verilmesini doğru bulmamaktayız. Çünkü, içerik bakımından hukuka aykırı herhangi bir hususun öğretilmediği bir eğitim ve öğretim kurumunun gerekli izinler alınmaksızın açılması, sadece idari yaptırım uygulanmasını gerektiren bir husustur. İçerik itibarıyla hukuka aykırı olmayan ve suç teşkil etmeyen hususları öğretmeye yönelik olarak yürütülen bir faaliyet, ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmez. Bu mülahazalarladır ki, söz konusu madde, bilahare 17.4.2013 tarihli ve 6460 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır (m. 13).

Keza, “Şapka ve Türk harfleri” başlıklı 222. madde hükmüne de Kanun metninde yer verilmesini doğru bulmamaktayız. Söz konusu madde metninde çeşitli kanun adları belirtilmek suretiyle, bu kanunların içeriğine genel mahiyette bir yollamada bulunmaktadır. Bu şekildeki soyut suç tanımları, Anayasada ve Kanunun üçüncü maddesinde güvence altına alınan suçta kanunilik ilkesi ve özellikle belirlilik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Nitekim, bu husus, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nun TCK Tasarısına ilişkin 3.8.2004 tarih ve Esas: 1/593, Karar: 60 sayılı Raporunun IV numaralı paragrafında açık bir şekilde vurgulanmıştır²⁴². Bu mülahazalarladır ki, söz konusu madde, bilahare 2.3.2014 tarihli ve 6529 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır (m. 16).

Ayrıca, Hükümet Tasarısının 302. maddesinin gerekçesinde de açıkça belirtildiği gibi, söz konusu Kanunlarda öngörülen yükümlülüklerle belirli suretteki aykırı davranışların yine bu Kanunlar kapsamında özel olarak yaptırım altına alınması daha yerinde olacaktır.

²⁴¹ TCK, m. 301’de 30.4.2008 tarihli ve 5709 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak, madde metninde yer alan söz konusu ibareler, önerimiz doğrultusunda değiştirilmiştir.

²⁴² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 227.

XX. Yeni TCK Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İktidar Partisi ile Anamuhalefet Partisinin uzlaşmasıyla kabul edilmiştir. Bu uzlaşmacı tutumun devam ettirilmesi uğruna, Kanun metninde yer alan bazı hükümler, hukuk tekniği bakımından uygun bir şekilde ifade edilmemişlerdir.

Bu hükümlere örnek olarak, yeni TCK'nın eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ve inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (m. 112, 113, 115) suçlarını örnek olarak gösterebiliriz.

Keza, “*Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma*” başlıklı 219. maddesi bu bağlamda bir örnek olarak zikredilebilir. Yeni TCK'nın, 765 sayılı Kanundan (m. 241 ve 242) iktibas edilen 219. maddesinde kabul edilen yaptırımlar, Kanunun Genel Hükümler Kitabında kabul edilmiş olan yaptırım sistemiyle de bağdaşmamaktadır.

Ayrıca, belirtmek gerekir ki, yeni TCK'nın İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “*Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk*” başlıklı Yedinci Bölüm altında yer alan suç tanımları da teknik bakımdan yanlışlıklar içermektedir. Hükümet Tasarısındaki şekliyle muhafaza edilen bu hükümlerde değişiklik yapılması yönündeki girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır.

Bu Bölümde yer alan 328 vd. maddelerde, “*Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler*” ifadesi kullanılmış iken; 334 vd. maddelerde ise, “*Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgiler*” ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca, “*Göreve ilişkin sırrın açıklanması*” başlıklı 258. maddesi hükmü de göz önünde bulundurulduğunda, bu sır kategorileri arasındaki ayırıcı ölçüyü belirlemek imkansızdır. Bu suçlarla ilgili olarak öngörülen cezalar arasındaki büyük fark, bu bakımdan hukuk güvenliğini sarsıcı niteliktedir.

Bütün bunlara rağmen, yeni TCK'nın kabulüyle, Türk Hukukunda büyük bir **reformun** gerçekleştiğini kabul etmek gerekir²⁴³.

²⁴³ İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.9.2012 tarihli ve E. 2010/283, K. 2012/245 sayılı (“*Balyoz Davası*”) Kararının temyizi amacıyla hazırlanmış olan dilekçe kitaplaştırılmış (1. Baskı – Mayıs 2013, ISBN 978 - 605 - 125 - 987 - 1) ve bu kitaba “sunum” yazısı yazılmıştır. Söz konusu “sunum” yazısının altında “*Duygun YARSUVAT*” isminin önünde “*Prof. Dr.*” unvanları kullanılmış ise de, bu yazının kaleme alınmasında akademik bir üslup kullanmamıştır. *Yarsuvat*, söz konusu “sunum” yazısında;

“*Almanya’da Max-Planck Enstitüsünde lisansüstü çalışmalarını yapan bazı genç hukukçuların da, Türk Ceza Kanunu ve Ceza muhakemesi Kanununu yazarken (Alman ceza hukukçusu Günterher Jakobs’un ortaya attığı “düşman ceza hukuku”ndan bahisle) bu görüşün etkisi altında kalarak Türk Ceza Hukukuna düşman ceza hukuku prensiplerini geçirdiklerini izlemekteyiz*”

ifadelerine yer vermiştir.

Yarsuvat, bu yazısında özellikle yeni Türk Ceza Kanununun TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında yazım görevini ifa etmiş bir kişi olarak şahsını hedef almıştır.

§8. Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi

Türk ceza hukukunun kaynaklarıyla ilgili olarak yaptığımız açıklamalarda görüldüğü üzere, ceza hukukuna ilişkin hükümler sadece TCK’da bulunmamaktadır. Çok sayıda kanun içerisinde suç tanımlarına veya ceza hukukuna ilişkin sair hükümlere yer verilmiştir.

765 s. mülga TCK’nın 10. maddesi, bu Kanunun genel mahiyetteki hükümleri ile, çeşitli konulara ilişkin düzenleme getiren diğer kanunlardaki özel hükümler arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir:

«Bu kanundaki hükümler, hususî ceza kanunlarının buna muhalif olmayan mevaddı hakkında da tatbik olunur.»

Buna göre; bir konuda diğer kanunlarda özel bir hüküm mevcut ise; TCK’nın genel mahiyetteki hükümlerinin, bu konuyla ilgili olarak uygulama kabiliyeti olmayacaktır.

765 s. TCK’nın bu hükmüne paralel bir düzenleme de, 1632 s. *Askeri Ceza Kanununda* bulunmaktadır:

«Türk Ceza Kanununa göre cürümler ve cezalar hakkında umumi surette cari esaslar, bu kanunda hilâfi yazılı olmadıkça askeri cürümler ve cezalar hakkında da tatbik olunur.» (m. 1).

As. CK, Türk Ceza Kanununa nazaran özel bir kanun niteliğindedir. Bu itibarla, TCK’nın genel hükümleri, As. CK’ndaki suç tanımlarıyla ilgili olarak, ancak bu Kanunda aksine düzenleme bulunmayan hallerde uygulanabilecektir²⁴⁴.

Yeni TCK’da ise, bu sistem tamamen değiştirilmek istenmiştir. Yeni TCK’nın “Özel kanunlarla ilişki” başlıklı 5. maddesi hükmüne göre;

«Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.»

Yarsuvat’ın, “düşman ceza hukukunda failin kusurunun önemi yoktur” belirlemesinde bulunduktan sonra, yeni Türk Ceza Kanununda hangi düzenlemelerin kusura dayalı sorumluluk ilkesiyle çelişerek, ya da malum “düşman ceza hukuku”na ilişkin hangi “ilke”ler esas alınarak kaleme alındığını somut olarak göstermesi gerekmez miydi?

Aslında bu “sunum” yazısında önemli bir çelişki bulunmaktadır. Bir yandan “Düşman ceza hukuku”ndan, öte yandan da bu hukuka ilişkin “ilkeler”den söz edilmektedir. Aslında malum “düşman ceza hukuku” telakkisi, ceza hukukuna ilişkin pek çok prensibin ihlalinin “meşrulaştırma” çabasını ifade etmektedir. Kural ihlallerine dayalı bir düşüncenin “ilkeler”inden bahsedilmesi doğru olmamıştır.

Aslında *Yarsuvat*’ın yeni TCK ile ilgili rahatsızlığının temelinde, Kanunun **dava zamanasını kesmeye ilişkin hükümleri** yatmaktadır. Bu bağlamda, TCK’nın 67. maddesinin iki ilâ dördüncü fıkralarında düzenlenen dava zamanasının kesilmesine ilişkin hükümlere yönelik olarak kitabımızın ilgili kısmında yapmış bulunduğumuz açıklamalara bakılmalıdır.

²⁴⁴ ERMAN, Sahir: *Askeri Ceza Hukuku, Umumi Kısım ve Usul*, 7. bası, İstanbul, 1983, sh. 4 vd.

Yeni TCK'ya ilişkin Hükümet Tasarısının 765 s. Kanuna paralel düzenleme getiren 3. maddesi TBMM Adalet Komisyonunda değiştirilerek 5. madde olarak kabul edilmiş ve madde metni, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen şekliyle kanunlaşmıştır. Maddenin **gerekçesi**, bu hükmün içeriğini yeterli ölçüde açıklayıcı niteliktedir:

«Özel ceza kanunlarında ve ceza içeren kanunlarda suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, çoğu zaman örneğin teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konularda da bu kanunda benimsenen ilkelerle çelişen hükümlere yer verilmektedir. Böylece, ceza kanununda benimsenen genel kurallara aykırı uygulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanılmaktadır. Tüm bu sakıncaların önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk uygulamasında birliği ve hukuk güvenliğini sağlamak için; diğer kanunlarda sadece özel suç tanımlarına yer verilmesi ve bu suçlarla ilgili yaptırımların belirlenmesi ile yetinilmelidir. Buna karşılık, suç ve yaptırımlarla ilgili olarak bu kanunda belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tanımlanan suçlar açısından da uygulanmasının temin edilmesi gerekmektedir. Aksi yöndeki düzenlemelerin hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturması nedeniyle Hükümet Tasarısındaki madde metni değiştirilmiştir.»²⁴⁵.

Bu düzenleme karşısında, yeni TCK'nın genel yürürlük tarihi olan **1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan diğer kanunlarda** yer alan, çeşitli suç tanımlarının yanı sıra, örneğin teşebbüse, iştirake, suçların içtimaına, sorumluluğun esaslarına, müsadereye, “fer’î ceza” olarak kamu hizmetlerinden yasaklılığa, cezanın ertelenemeyeceğine veya para cezasına çevrilemeyeceğine ilişkin hükümler, bu tarihte zımnen ilga edilmiş olacaktır.

Ancak, ilgili kanunlarda TCK'nın sistemine uygun gerekli değişiklikleri hemen gerçekleştirme imkanının olmaması nedeniyle, bu hükmün ülkemiz hukuk uygulamasında ortaya çıkarabileceği sonuçlar kaygı verici görülmüştür. Bu nedenle, 11.5.2005 tarihli ve 5349 sayılı Kanunla²⁴⁶ *Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna bir geçici madde* eklenmiştir. Bu maddeye göre;

“Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılmıyaya ve en geç 31 Aralık 2006²⁴⁷ tarihine kadar uygulanır.”

²⁴⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 408.

²⁴⁶ RG: 18 Mayıs 2005/25819.

²⁴⁷ Ancak, söz konusu geçici madde metninde yer alan “31 Aralık 2006” ibaresi, 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla “ilgili kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılmasına imkân sağlamak amacıyla” “**31 Aralık 2008**” olarak değiştirilmiştir (m. 15).

Bu hükmün gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

"765 sayılı Türk Ceza Kanununun 10 uncu maddesindeki "Bu kanundaki hükümler, hususi ceza kanunlarının buna muhalif olmayan mevaddı hakkında da tatbik olunur," hükmü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, ceza hukuku sistemini belirli bir disiplin altında toplamak amacıyla, 5'inci maddede "Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır." şeklinde düzenlenmiştir.

5'inci maddesindeki hüküm karşısında, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümlerine uymayan hükümlerin uygulanma kabiliyeti kalmadığından, söz konusu kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

*Söz konusu değişiklikler yapıncaya kadar uygulamada herhangi bir boşluğun doğmaması bakımından 5252 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi amacıyla bu madde düzenlenmiştir."*²⁴⁸.

Bu zaman zarfında, yeni Türk Ceza Kanununun genel hükümlerine uyarlanması amacıyla pek çok kanunda değişiklik yapılmış ve hatta bazı kanunlar tamamen değiştirilmiştir²⁴⁹.

TCK'nın 5. maddesi hükmü **31.12.2008** tarihinde yürürlüğe girdiğine göre, bu tarihten önce yürürlüğe girmiş olan kanunlarda yer alıp da TCK'nın genel hükümlerine aykırı olan düzenlemelerin artık zımnen ilga edilmiş olduğunu kabul etmek gerekir. Bu itibarla, 5 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 27.12.2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 20. maddesinde, koruma altına alınan kişilerle ilgili bilgilerin gizliliğini ihlal eden kişi, **"fîl(i) başka bir suç oluştursa bile ayrıca, Türk Ceza Kanununun 258'inci maddesi hükmüne göre cezalandırılır."** hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümle, kişinin işlediği **bir fiilden dolayı iki defa cezalandırılmasına** imkan tanınmıştır. TCK'nın farklı neviden fikri içtimai düzenleyen 44. maddesi hükmüne açıkça aykırı olan bu düzenleme, 31.12.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5. madde hükmü karşısında zımnen ilga edilmiştir^{250,251}.

²⁴⁸ Bkz. TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 898.

²⁴⁹ Örneğin, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çıkarılmış ve 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer kanunlarda yer alan düzenlemelerin yeni Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanununun genel hükümlerine uyarlanması amacıyla gerekli yasama çalışmaları tamamlanmış ve TBMM Genel Kurulunda 23.1.2008 tarihinde kabul edilen **5728 sayılı Kanun**, 8 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 580 madde ve 3 geçici maddeden ibaret olan bu Kanun ile toplam **153** değişik **kanunda değişiklik** yapılmıştır.

²⁵⁰ Yeni TCK'nın 5. maddesi hükmü karşısında bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra, 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun pek çok hükmü zımnen ilga edilmiş olacaktı. Askeri Ceza Kanununda da, yeni TCK'nın suç ve yaptırım teorisine ilişkin genel hükümlerine

Önemle belirtmek gerekir ki; yeni TCK’nın 5. maddesi hükmü, “*genel norm – özel norm*” ilişkisinde uygulanamaz.

TCK’da yer alan suç tanımlarıyla diğer kanunlarda yer alan suç tanımları arasında “*genel norm – özel norm*” ilişkisinin varlığı halinde, *aynı hukuki değeri* ihlâl niteliği taşıyan iki suç söz konusudur. Ancak, özel nitelikteki suç tanımlarında ilave birtakım unsurlara da yer verilmektedir. Aynı hukuki değeri ihlâl niteliği taşımakla birlikte, başka bir kanunda TCK’daki suça nazaran ayrı bir suç tanımına yer verilmesi durumunda, “*özel normun önceliği ilkesi*” gereğince, sair kanundaki özel suç tanımı uygulama kabiliyetini haiz olacaktır²⁵².

Bir özel hukuk tüzelkişisi olan bankalara ait para ve sair malvarlıklarının banka görevlilerince zimmete geçirilmesi fiilleri aslında TCK’da tanımlanan “emniyeti suistimal” (güveni kötüye kullanma) suçunun nitelikli halini oluşturmaktaydı (mülga 765 s. TCK, m. 508, 510: “hizmet sebebiyle emniyeti suistimal”). Ancak, bu fiiller 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı “Bankalar Kanunu”nda özel bir “*zimmet suçu*” olarak tanımlanmıştır (m. 22, f. 3, 4). Keza, 4389 s. Kanunu yü-

uygun olarak gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Ancak, bu değişiklikler, yeni TCK’nın yürürlük tarihi olarak önce belirlenen 1 Nisan 2005 tarihine yetiştirilemediği için, **31.3.2005 tarihli ve 5329 sayılı Kanunla** (RG: 6 Nisan 2005/25778), Askeri Ceza Kanunundaki bazı hükümler saklı tutulmuştur (8 ve 9. Ek maddeler):

“EK MADDE 8- 26.9.2004 tarihli ve 5327 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri bu Kanunda yer verilen suçlar hakkında da uygulanır. Ancak, bu Kanunun fer’i askeri cezalara ve cezaların ertelenmesine ilişkin hükümleri ile zamanaşımına ilişkin 49’uncu maddesinin (A) bendi hükümleri saklıdır.

Sırf askeri suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile ön ödeme hükümleri uygulanmaz.

Kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılma veya bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına dair güvenlik tedbirleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında, öngörülen süre kadar açığa çıkarılma şeklinde uygulanır. Yedek subaylar ile erbaş ve erler hakkında bu tedbirin uygulanması, askerlik hizmetlerinin tamamlanmasından sonra yerine getirilir.

Yedek subaylar hariç olmak üzere subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel hakkında, askeri ve adliye mahkemelerince verilen kısa süreli hapis cezaları Türk Ceza Kanununun 50’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde yazılı olanlar dışındaki seçenek yaptırımlara çevrilemez.”

“EK MADDE 9- Bu Kanunda alt sınırı belirtilmeyen ağır hapis cezalarının alt sınırları ‘bir sene’ olarak uygulanır”

Ancak, belirtmek gerekir ki, Askeri Ceza Kanununa eklenen bu hükümlere rağmen, kanaatimizce, **Askeri Ceza Kanununda yer alan yeni TCK’nın “Genel Hükümler” başlıklı Birinci Kitabındaki düzenlemelere aykırı hükümler, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ilga edilmiştir ve bu tarihten sonra söz konusu hükümlerin uygulama kabiliyeti kalmamıştır.**

²⁵¹ 25.10.1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, m. 25’de yer alan suç tanımlarına ilişkin hükümlere özellikle bakılmalıdır.

²⁵² Bkz. İÇEL, Kayıhan: *Suçların İçtimai*, İstanbul, 1972, sh. 186; İÇEL/DONAY, 3. bası, sh. 65, 66.

rürlükten kaldıran 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı **Bankacılık Kanununda**²⁵³ da özel “zimmet suçu” tanımına yer verilmiştir (m. 160). Bu düzenleme karşısında; özel hukuk tüzel kişisi bankaların bu fiilleri işleyen görevlileri hakkında, artık TCK’da tanımlanan güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler (5237 s. TCK, m. 155, f. 1 ve 2) değil, 5411 sayılı Kanundaki bankacılık zimmeti suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır²⁵⁴.

Ayrıca, üzümlere itiraf etmemiz gerekir ki; **Anayasada, normlar hiyerarşisinde kanundan önce temel kanun kategorisine yer verilmediği için, yeni TCK’nın 5’inci maddesi hükmünün, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren çıkarılan ve çıkarılacak olan kanunlar bakımından mevzuat disiplini sağlama yönünden bir etkisi olamayacaktır**²⁵⁵.

²⁵³ RG: 01 Kasım 2005/25983 Mükerrer.

²⁵⁴ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, sh. 150.

²⁵⁵ Ayrıca bkz. KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 10. bası, Ankara, Eylül 2017, sh. 47 vd.

§9. Suçların Tasnifi Sorunu – Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması

Çeşitli ceza kanunlarında suçlar, *ifade ettikleri haksızlık muhtevası itibarıyla* iki veya üçlü tasnife tabi tutulmuşlardır.

Eski kanunlarda bu konuda üçlü ayırım kabul edilmekteydi. Buna göre suçlar, *cürüm*, *cünha* ve *kabahat* olarak üçe ayrılmaktaydı. Meselâ, 1810 Fransız (Napolyon) Ceza Kanununda (m. 1) bu ayırım benimsenmişti. Büyük ölçüde bu Kanundan iktibas edilen 1274 (1858) Osmanlı Ceza Kanunname-i Hümayunu’nda da bu ayırım benimsenmişti.

1871 Alman Ceza Kanununda, başta bu üçlü ayırım benimsenmişti. Fakat, kabahatleri ceza hukuku anlamında suç olmaktan çıkarma eğiliminin etkisiyle, 1975 yılında bu Kanunda yapılan değişikliklerle, kabahat türünden fiiller, suç olmaktan ve dolayısıyla, ceza kanunundan çıkarılmıştır. Bu fiiller, Alman hukukunda “*düzene aykırılıklar*” olarak nitelendirilerek, sadece idari ceza yaptırımı (idari yaptırım) uygulanmasını gerektiren fiiller olarak tanımlanmışlardır. Bugün Alman Ceza Kanununda suçlar *cürüm* ve *cünha* olmak üzere iki grupta tasnif edilmiştir.

765 s. mülga TCK’da ise, kaynak 1889 İtalyan Ceza Kanununda olduğu gibi, suçlar *cürüm* ve *kabahat* olarak iki grupta tasnif edilmişti. Kanun, “Kitap” olarak ifade edilen üç ana bölümden müteşekkildi. “*İkinci Kitap*” cürümlere ayrılmış iken, “*Üçüncü Kitap*”ta kabahatler yer almaktaydı. Yeni bir Türk Ceza Kanunu hazırlık çalışmalarının ürünü olan 2003 Tasarısında da cürüm ve kabahat ayırımına sadık kalınmıştı. Ancak, Tasarıda, kabahatleri ceza hukuku anlamında suç olmaktan çıkarma eğiliminin etkisiyle, bazı kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması düşüncesi benimsenmişti. 765 s. TCK’nın 527, 529, 531, 533-535, 538-545, 548, 550, 556-562, 570, 575-581 ve 584. maddelerinde kabahat türünden suç olarak tanımlanan fiiller, Tasarıda suç olmaktan çıkarılmıştı. Bu kapsamda, dilencilik fiilleri²⁵⁶ ile akıl hastaları üzerindeki nezaret görevinin gereklerinin yerine getirilmemesi²⁵⁷, 765 s. TCK’da kabahat türünden suçlar olarak tanımlanmasına rağmen, Tasarıda suç olmaktan çıkarılmıştı.

²⁵⁶ 765 s. mülga TCK’nın ilgili hükümleri şöyleydi:

MADDE 544- Her kim, çalışmaya muktedir olduğu halde dilencilik ederken tutulursa bir haftadan bir aya kadar **hafif hapis cezası**yle cezalandırılır.

Tekerrürü halinde **hafif hapis cezası** bir ayadan aşağı olamaz.

MADDE 545- Her kim, 15 yaşından aşağı çocukları toplayıp dilencilik ettirir veya velâyet ve vesayeti altında bulunan yahut kendisinin muhafazası ve nezaretine tevdi olunan 15 yaşından aşağı bir küçüğün dilenmesine veya bir kimsenin o küçüğü dilencilikte kullanmasına müsaade ederse üç aydan aşağı olmamak üzere **hafif hapis** ve yüz liradan aşağı olmamak üzere **hafif para cezası** ile cezalandırılır.

²⁵⁷ 765 s. mülga TCK’nın ilgili hükümleri şöyleydi:

MADDE 560- Muhafazası altında bulunan delileri serbest bırakan yahut muhafızı olduğu deliler kurtulup kaçtıkları zaman derhal ait olduğu daireye malûmat vermiyen kimse yirmi beş liraya kadar **hafif cezayı nakdiye mahkûm olur**.

Keza, belirtmek gerekir ki, Tasarıda, kabahatler, ayrı bir bölüm altında değil, cürümlerin arasına serpiştirilmek suretiyle tanımlanmışlardı.

765 s. mülga TCK'da kabahat türünden suç olarak tanımlanmış olan bazı fiiller, Tasarıda bu özelliğini muhafaza etmişlerdi²⁵⁸.

765 s. mülga TCK'da cürüm türünden suç olarak tanımlanmış olan bazı fiiller²⁵⁹, Tasarıda kabahat türünden suç olarak tanımlanmıştı²⁶⁰.

TCK Tasarısında 765 s. mülga TCK'da yer almayan kabahat türünden suç tanımlarına da yer verilmişti. “Taksirle zarar verme” başlıklı 214. madde²⁶¹ ve “Bilgi vermeme” başlıklı 227. madde²⁶² bu hükümlere örnek olarak gösterilebilir.

MADDE 561- Her kim, ait olduğu daireye derhal malûmat vermeksizin ve mezuniyet lâzım gelen hususatta mezuniyet almaksızın akıl hastalığına müptelâ olduğunu bildiği bir kimseyi muhafaza için kabul eder veya böyle bir kimseyi kendi başına bırakırsa beş liradan elli liraya kadar **hafif cezayı nakdiye mahkûm olur ve buna ahvalin vahametine göre bir aya kadar hafif hapis cezası da ilâve olunur.**

MADDE 562- Fail bir tımarhane müdürü veya tababet mesleği mensuplarından birisi olduğu takdirde geçen maddelerde yazılı cezalara **meslek ve sanatın tatili cezası** dahi ilave olunur.

²⁵⁸ Örneğin, Tasarının “Sağlık mesleği mensuplarınca cürmün haber verilmemesi” başlığını taşıyan 472. maddesi hükmü ise şöyleydi:

“Hekim, ebe veya diğer sağlık meslekleri mensupları, kişilere karşı işlenmiş bir cürüm belirtisi gösteren hâllerde, mesleklerinin gerektirdiği yardımı yaptıktan sonra durumu adliye veya kolluğa bildirmez veya ihbar hususunda gecikirlerse, bu ihbarın kendisine yardım edilen kimseyi soruşturmaya veya kovuşturmaya uğratacağı hâller dışında üçyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar **hafif para cezası** verilir.”

765 s. mülga TCK'nın bu hükmün karşılığı olan 530. maddesi şu şekilde idi:

“Hekim, cerrah, ebe yahut sair sıhiye memurları eşhas aleyhinde işlenmiş bir cürüm asarını gösteren ahvalde sanatlarının icabettiği yardımı ifa ettikten sonra keyfiyeti adliye veya zabıtaya bildirmezler yahut ihbar hususunda teahhur gösterirlerse -bu ihbar kendisine yardım ettikleri kimseyi takibata maruz kılacak ahval müstesna olmak üzere- otuz liraya kadar **hafif cezayı nakdiye mahkûm olurlar.**”

²⁵⁹ 765 s. mülga TCK'nın 297. maddesi hükmü şu şekilde idi:

“Maktulün cesedini saklayan veya saklatan veya Hükümete haber vermeksizin ve keşfolunmaksızın gömen ve gömdüren kimseler üç aydan bir seneye kadar **hapis** ve elli liraya kadar **ağır cezayı nakdî ile cezalandırılır.**”

²⁶⁰ Tasarının “Şüpheli ölüm hâlinde cesedin muayenesini yaptırmama” başlıklı 457. maddesi hükmü şu şekilde idi:

“Adli soruşturmayı gerektirebilecek hâllerde, cesedi saklayan veya saklatan veya yetkili makamlara haber vermeden ve muayenesi yapılmadan gömen veya gömdürenlere üç aydan bir yıla kadar **hafif hapis cezası** verilir.”

²⁶¹ “Bir kimsenin etrafı işaretlendirilerek sınırlanmış arazisindeki bitkilere veya bağ veya bahçesine **taksirle zarar veren** kimseye zarar görenin şikâyeti üzerine zararın iki katı **hafif para cezasına** ve ayrıca zararın ödettirilmesine re'sen karar verilir.”

²⁶² “Para veya eşyayı herhangi bir suretle eline geçirdikten sonra, bunların menşeinin hukuka aykırı olduğunu anlayıp da merciine derhal bilgi vermekte ihmalde bulunan kimseye üçyüzellimilyon liradan birmilyar liraya kadar **hafif para cezası** verilir.”

765 s. mülga TCK'ya göre, bir suçun cürüm veya kabahat türünden bir suç olduğu, o suçla ilgili olarak kanunda öngörülen *ceza yaptırımının niteliğine* bakmak suretiyle belirlenebilirdi. 765 s. Kanunun sistematigi de bu konuda bir kolaylık sağlamaktaydı. Zira, Kanunun İkinci Kitabında, cürüm türünden suçlar; Üçüncü Kitabında ise, kabahat türünden suçlar tanımlanmıştı²⁶³. Özel kanunlarda tanımlanan suçlar bakımından, belirleyici münhasır kıstası, suçun karşılığında öngörülen yaptırımın türü oluşturmaktaydı. 765 s. Kanunun 11. maddesi hükmüne (f. 1 ve 2) göre;

«(1) *Cürümlere mahsus cezalar şunlardır:*

1- *İdam,*

2- *Ağır hapis,*

3- *Hapis,*

...

5- *Ağır cezayı nakdi,*

6- *Hidematı âmmeden memnuiyet.*

(2) *Kabahatler için mevzu cezalar şunlardır:*

1- *Hafif hapis,*

2- *Hafif cezayı nakdi,*

3- *Muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası.»*

Ancak, belirtmek gerekir ki, 765 s. Kanunun sisteminde cezalar, 19. yüzyıl ceza hukukunun etkisiyle, “*asli cezalar*” ve “*fer’î cezalar*” olarak iki grupta mütalaa edilmekteydiler. Halbuki, “*fer’î ceza*” olarak nitelendirilen yaptırımlar, aslında *güvenlik tedbiri* niteliği taşımaktadırlar ve ceza mahkûmiyetinin kanunî neticesi olarak mütalaa edilmelidirler. Bu nedenledir ki, 11. madde hükmünde meselâ, “*muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası*”, kabahatler için öngörülmüş bir “ceza” olmasına rağmen; bu yaptırıma cürüm niteliği arzeden bazı suç tanımlarında da “fer’î ceza” olarak yer verilmişti (TCK, m. 406, f. 1 ve 2).

Bu sistemde, kanunda belirlenmiş olan ceza miktarları dikkate alınmadığı için, bu miktarlarda yapılan değişiklikler de kabahat türünden bir suçu cürüm veya cürüm türünden bir suçu kabahat olarak nitelendirmeye imkan tanımaz. Bu sis-

²⁶³ Ancak belirtelim ki, 765 s. Kanunun kabahatleri düzenleyen Üçüncü Kitabında yer almakla beraber, 537. maddenin 9. fıkrasında tanımlanan suç, atıfta bulunulan hüküm ve dolayısıyla öngörülen ceza yaptırımı itibarıyla, cürüm olarak kabul edilmek gerekir (Aynı yönde görüş için bkz. ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 145). Bu nedenle, söz konusu fıkra da tanımlanan suçun kabahat türünden bir suç olduğu yönündeki görüşe (CENTEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 162, dn. 61) iştirak etmiyoruz.

²⁶⁴ Maddenin “*sürgün*” cezasını öngören dördüncü bendi, 13.7.1965 tarih ve 647 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

temde, kabahat için öngörülmüş olan “hafif para cezası”nın miktarı, cürüm için öngörülmüş olan “ağır para cezası”na nazaran çok daha fazla olabilir²⁶⁵.

765 s. Kanunda suçlar arasında yapılan bu cürüm ve kabahat ayırımına birtakım hukuki sonuçlar bağlanmıştı.

Meselâ cezaların ertelenmesinde cürümlerle kabahatler bakımından farklı deneme süreleri öngörülmüştü (765 s. TCK, m. 95); cürümlerle kabahatler arasında tekerrür hükümleri uygulanmamaktaydı (765 s. TCK, m. 87); cürümlere teşebbüs cezalandırılabilir iken, kabahatlere teşebbüs cezalandırılmamaktaydı (765 s. TCK, m. 61 ve 62). Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına dönüştürülmesinde bir güne tekabül eden para miktarı bakımından cürümlerle kabahatler arasında bir ayırım yapılmıştı (647 s. –mülga– CİK, m. 4, f. 1). Adli sicil kaydının silinmesi açısından da cürümler ve kabahatler açısından farklı süreler öngörülmüştü (22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı –mülga– Adli Sicil K, m. 8).

765 s. Kanunda, suçun manevi unsuru bakımından da cürümlerle kabahatler arasında ilginç ayırıma yer verilmişti. Buna göre, cürümler kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Eğer kanunda açıkça cürüm olarak tanımlanmış ise, taksirle işlenen fiil dolayısıyla fail cezalandırılabilir (765 s. TCK, m. 45, f. 1). Buna karşılık, kabahatlerde ise, failin cezalandırılabilmesi için, suç teşkil eden fiilin gerçekleşmiş olması yeterli sayılmıştı. Kabahat türünden bir suçun işlenmesi açısından failin kasten mi yoksa taksirle mi hareket ettiğinin araştırılmasına gerek yoktu (765 s. TCK, m. 45, f. 2). Objektif sorumluluk rejiminin benimsendiği 19. yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir ürünü olan bu düzenleme doğru değildi²⁶⁶. Aslında bu düzenleme, kabahat türünden bir suç işleyen kişi aleyhine olan bir sonuç ortaya çıkarmaktaydı. Şöyle ki, meselâ bir başkasının malvarlığına taksirle zarar verilmiş olması durumunda kişi cezalandırılmayacaktır. Çünkü, başkasının malvarlığına zarar verme (nası ızrar) suçu ancak kasten işlenebilir (765 s. TCK, m. 516; 5237 s. TCK, m. 152). Buna karşılık, başkasına ait binanın duvarlarına afiş yapıştırmak, yazı yazmak gibi fiiller dolayısıyla, failin cezalandırılabilmesi için kastının sabit olması gerekmemekteydi (765 s. TCK, m. 536)^{267,268}.

²⁶⁵ Buna karşılık, Alman hukukunda bir suçun cürüm veya cünha olarak ayırımında hem cezanın miktarı hem de niteliği göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre; en az bir yıl veya daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı gerektiren hukuka aykırı fiiller, cürümdürler. Bu sınırdan daha az süreyle hürriyeti bağlayıcı cezayı ya da para cezasını gerektiren hukuka aykırı fiiller ise, cünhaları oluşturmaktadır (Alman CK, § 12).

²⁶⁶ TCK Tasarısında da aynı içerikte hükme yer verilmişti (m. 22):

«Kabahatlerde kast olmasa bile, herkes kendi icra veya ihmalden sorumludur.».

²⁶⁷ 765 s. TCK’nın isteminde cürüm ve kabahat ayırımının sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 141 vd.

²⁶⁸ Alman hukukunda cürümlere teşebbüs, cezalandırılabilir hukuka aykırı fiil olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık, cünhalara teşebbüsün cezalandırılabilmesi için, kanunda ilgili suç ta-

765 s. Kanundan farklı olarak, yeni TCK’da, suçlar arasındaki “cürüm” ve “kabahat” ayrımı kaldırılmıştır. 765 s. Kanunda yer alan bazı “kabahat”ler, suç olarak metinde muhafaza edilmiştir. Böylece hukuk sistemimizde “cürüm” ve “kabahat” ayrımı kaldırılmıştır. Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunlarda artık “cürüm” tabiri kullanılmamaktadır. Ancak, eski kanunlarda geçen “cürüm” ibaresi, artık bundan böyle suç olarak anlaşılmalıdır. Yeni TCK’da “bir suç türü” olarak “kabahat”e yer verilmemiştir. Ancak, bu durum, **suç oluşturmamakla birlikte haksızlık ifade eden belirli fiillerin kabahat olarak tanımlandığı ve bu haksızlıklarla ilgili genel hükümlerin yer aldığı ayrı bir kanuna ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.** 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı **Kabahatler Kanunu**, bu ihtiyacı karşılamaktadır²⁶⁹.

Suçlarla kabahatler arasındaki ayrımın mahiyeti, kabahatlerle ilgili olarak TCK’nın genel hükümlerinin ne ölçüde uygulama kabiliyetine sahip bulunduğu, kabahat türünden haksızlıklar karşılığında uygulanan yaptırımların mahiyeti hakkında ayrıntılı bilgi içermesi dolayısıyla, **Kabahatler Kanununa** ilişkin Tasarının **Genel Gerekçesini** aynen iktibasında fayda mülâhaza edilmiştir.

“Haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili olmaktadır. Ancak, bir fiilin suç veya kabahat

nımı kapsamında bu hususta açık bir hüküm bulunması gerekir (Alman CK, § 23, f. 1). Keza, akim kalmış olan azmettirme cürümlerde cezalandırılabilir bir fiil olma özelliğini taşıırken; cünhalarda cezalandırılmamaktadır (Alman CK, § 30). Söz konusu cürüm ve cünha ayırımına muhakeme hukuku açısından da çeşitli sonuçlar bağlanmıştır. Bu hususta bkz BAUMANN, Jürgen/WEBER, Ulrich//MITSCH, Wolfgang: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch*, 10. Auflage, Bielefeld, 1995, sh. 174/175; JESCHECK, Hans Heinrich: *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, Berlin, 1988, sh. 49 vd.

²⁶⁹ Ancak, işaret etmek gerekir ki, **Anayasa Mahkemesi**, 1.3.2006 tarihli ve E. 2005/108, K. 2006/35 sayılı Kararında (RG: 22 Temmuz 2006/26236) yeni TCK ile Kabahatler Kanununun bu sistemine rağmen kabahatlerin de bir suç türü oluşturduğunu kabul etmektedir:

«Ceza hukukundaki gelişmelere koşut olarak, kimi yasal düzenlemelerde **basit nitelikte görülen suçlar** hakkında idari yaptırımlara yer verildiği görülmektedir.

...

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun İkinci Kısımında “Çeşitli kabahatler” başlığı altında düzenlenen fiilleri, ağırlıklı olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 526. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan kabahatler oluşturmaktadır. 5252 sayılı Yasa’nın 7. maddesiyle, çeşitli yasalarda hafif hapis veya hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımlar idari para cezasına dönüştürülmüştür. Yaptırımın adının yasa ile “idari” olarak değiştirilmesinin, bu tür yaptırım uygulanacak eylemlerin **gerçekte ceza hukuku alanına giren suç olma özelliklerini etkilemeyeceği** açıktır.»

Aynı düşünce, Anayasa Mahkemesi’nin 12.4.2006 tarihli ve E. 2006/58, K. 2006/50 sayılı Kararında da (RG: 1 Eylül 2006/26276) tekrarlanmıştır.

Kabahatler Kanununun Genel Gerekçesinde yer alan açıklamalar dikkate alındığında, **bu değerlendirmenin doğru olmadığı** anlaşılabacaktır. Nitekim, 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un 8. maddesinin onikinci fıkrasında, söz konusu Kanunda tanımlanan ve idari para cezasını gerektiren fiiller **kabahat** olarak nitelendirilmiştir.

olarak tanımlanmasında, bunun esasen haksızlık ifade etmesi gerektiği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Esas itibarıyla haksızlık ifade etmeyen, hukuka aykırı olmayan bir fiil hiçbir surette suç veya kabahat olarak tanımlanamaz.

Haksızlıklar arasında bu yönde bir tasnif yapılması durumunda; bu tasnifte, hukuka aykırı olan fiilin ifade ettiği haksızlık içeriği esas alınmalıdır.

Bu bakımdan, esasen hukuka aykırı olan ve haksızlık ifade eden fiiller arasında suç veya kabahat olarak bir ayırım yapılması, bir nitelik farkı oluşturmamaktadır. Söz konusu tasnif, haksızlıklar arasındaki nicelik farkına dayanmaktadır. Bu tasnif, haksızlıklar arasında sadece bir işlem farklılığı doğurmaktadır.

Örneğin, suçlar kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Eğer kanunda açıkça belirtilmişse, taksirle işlenen fiil de istisna olarak suç oluşturabilir. Buna karşılık, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahat türünden haksızlıklar kural olarak hem kasten hem de taksirle işlenebilirler. Ancak, sadece kasten veya taksirle işlenebilen fiilin kabahat oluşturabileceği konusunda kanunda hüküm bulunabilir.

765 sayılı Türk Ceza Kanununun sistemine göre, failin cezalandırılabilmesi için, kabahat teşkil eden fiilin gerçekleşmiş olması yeterli sayılmıştır. Kabahat türünden bir suçun işlenmesi açısından failin kasten mi yoksa taksirle mi hareket ettiğinin araştırılmasına gerek yoktur (m. 45, f. 2). Objektif sorumluluk rejiminin benimsendiği 19'uncu yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir ürünü olan bu düzenlemenin doğru olmadığını ifade etmek gerekir. Aslında bu düzenleme, kabahat türünden bir suç işleyen kişi aleyhine olan bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki, örneğin bir başkasının malvarlığına taksirle zarar verilmiş olması durumunda kişi cezalandırılmayacaktır. Çünkü, başkasının malvarlığına zarar verme (nası zarar) suçu ancak kasten işlenebilir (m. 516). Buna karşılık, kamu makamlarından gerekli izin alınmaksızın başkasına ait binanın duvarlarına afiş yapıştırmak, yazı yazmak gibi fiiller dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için kastının sabit olması gerekmemektedir (m. 536).

Keza, suça teşebbüs cezalandırılabilir iken, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahate teşebbüs kural olarak cezalandırılmamaktadır. Suça iştirakte suç ortakları arasında fail ve şerik (azmettiren veya yardım eden) ayırımı yapılmaktadır. Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahate iştirakte ise, tek tip fail sistemi kabul edilmiştir.

Tekerrür bakımından da suçlarla kabahatler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarının kapsamı dışına **çıkarma eğiliminin** bir sonucu olarak; çeşitli hususlarda düzenleme getiren özel kanunlarda bazı fiiller karşılığında idari yaptırımlar öngörülmektedir. Başka bir deyişle, bu fiiller, "idari suçlar" olarak tanımlanmaktadırlar.

Bu fiiller karşılığında, genellikle parasal nitelikte bir yaptırım öngörülmektedir. Ancak, bu parasal yaptırım, bir ceza hukuku yaptırımı olan "adli para cezası"²⁷⁰ değil; idari yaptırım olarak "idari para cezası"²⁷¹ niteliği taşımaktadır.

Belirtmek gerekir ki, her ikisi de belli bir miktar paranın kişiden alınıp Devlet Hazinesine intikalinden ibaret gibi görünürse de; adli nitelikteki para cezası ile idari nitelikteki para cezası arasında, karar veren merci, yaptırımın infaz sureti, yaptırıma bağlanan kanunî neticeler bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Örneğin, idari nitelikte bir yaptırım olarak para cezasına, ceza muhakkemesi süreci sonucunda mahkeme tarafından hükmedilmez; bu ceza, idari görev yapan bir kişi veya kurul tarafından verilir. Bu cezalar, adli sicile kaydedilmez, ödenmediği takdirde hapse dönüştürülmez.

İdari nitelikteki "para cezası", bir uyarı (ikaz) fonksiyonu gördüğü gibi, kamu açısından oluşmuş olan zararın giderilmesi amacına da hizmet edebilir. Bu nedenle, idari para cezasının misli nitelikte olması mümkündür.

Özellikle ekonomik hayata ilişkin düzenlemeler kapsamında oldukça sık bir şekilde idari nitelikte ceza yaptırımlarına yer verilmektedir. Bu bağlamda yürürlüğe konan kanunlarda veya kanun hükmünde kararnamelerde kazuistik hükümlere yer verilmektedir. Bu kazuistik düzenlemeler arasında bir sistem birliğinin varlığından söz edilemez. Bunlar arasında bir ahenksizlik hakim bulunmaktadır. Bu nedenle, idari nitelikteki yaptırımlarla ilgili olarak genel bir kanuna ülkemiz açısından büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düşüncelerle hazırlanan bu Tasarıda, idari yaptırımları gerektiren fiiller yani kabahatler açısından kanunilik ilkesi, zaman bakımından uygulama ve sorumluluk esasları, zamanaşımı, idari yaptırımların hukuki niteliği, çeşitleri ve sonuçları, bu yaptırımların yerine getirilmesi rejimi gibi konular, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiştir.²⁷²

²⁷⁰ "Geldstrafe".

²⁷¹ "Geldbusse".

²⁷² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840, sh. 1 vd.

§10. Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu²⁷³

Ceza hukuku, kişi hak ve hürriyetleri üzerinde en fazla etkisi olan bir hukuk disiplini. Bu nedenledir ki, ceza hukuku uygulamasında kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almaya yönelik olarak, bazı prensipler kabul edilmiştir.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve *belirlilik ilkesi*, bu kapsamda üzerinde durulması gereken iki ana prensibi oluşturmaktadır. Ceza hukuku kurallarının yorumu ile kıyas arasındaki sınırın belirlenmesi, bu güvencenin sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

I. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi

Aydınlanma devrinin ceza hukukuna kazandırdığı bu ilke, ilk defa Fransız düşünür *Montesquieu* tarafından²⁷⁴ ifade edilmiş olup; 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisine de iktibas edilmiştir (m. 7 ve 8). Roma hukukunda tanınmamasına rağmen, suçta ve cezada kanunilik ilkesini Latince bir formülle ifade eden Alman ceza hukukçusu *Feuerbach* olmuştur: “*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*”²⁷⁵.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, aynı zamanda 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (m. 11, f. 2) ve 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinde (m. 7, f. 2) de kabul edilmiştir.

1982 Anayasasının “suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. maddesinde, suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması konusundaki ilkeler birlikte düzenlenmiştir. Buna göre,

“Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” (f. 1).

“Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.” (f. 2).

“Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” (f. 3).

²⁷³ Bu paragraf altında yer alan konulara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu”, in: Kamu Hukuku Arşivi, yıl 3, sayı 2-3, Haziran-Ekim 2000, sh. 90 vd.; ÖZGENÇ, İzzet/ŞAHİN, Cumhuriyet: *Uygulamalı Ceza Hukuku*, 3. bası, Ankara 2001, sh. 13 vd. ÖZGENÇ, TCK Gazi Şerhi, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 64 vd.; BOZ-BAYINDIR, Ali Emrah: *Kanunilik İlkesi ve Özel Ceza Kanunları*, İstanbul, Aralık 2013.

²⁷⁴ *Montesquieu*’nun fikirleri için bkz. OKANDAN, Recai Galip: *Umumî Âmm Hukuku*, İstanbul 1976, sh. 571 vd.

²⁷⁵ FEUERBACH, Paul Johann Anselm: *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts*, 14. Ausgabe, Gießen, 1847, § 23.

Yeni TCK'nın “*Suçta ve cezada kanunilik ilkesi*” başlıklı 2. maddesinde, bu ilke suç, ceza ve güvenlik tedbirleri bakımından vurgulandığı gibi, belirlilik ilkesi ve kıyas yasağı açık bir şekilde ifade edilmiştir:

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile, ceza hukuku uygulamasında devletin bireye karşı keyfi muamelede bulunmasının önlenmesi amaçlanmıştır^{276, 277}.

Suçta kanunilik ilkesi gereğince, kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez. Keza, kanunun açıkça cezayı arttırıcı bir neden olarak öngörmediği bir husustan dolayı da kimsenin cezası arttırılamaz. *Cezada kanunilik ilkesi* gereğince, hiç kimse belli bir suçla ilgili olarak kanunda öngörülmemiş bir ceza ile ya da kanunda öngörülen cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılmaz.

Suç, toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin açık ve bilinçli bir ihlali veya en azından bu değerleri korumaya matuf kurallara özensizlik niteliği taşıyan insan davranışlarıdır. Böylece, ancak esasen haksızlık teşkil eden insan davranışları, kanunlarda suç olarak tanımlanabilir. Esas itibarıyla hukuka aykırılık vasfı taşımayan, toplumsal hayat açısından vazgeçilmez değerlerin ihlali niteliği taşımayan insan davranışları, kanunlarda suç olarak tanımlanamazlar²⁷⁸. Ceza hukukunun güvence fonksiyonu kapsamında söz ko-

²⁷⁶ Anayasa Mahkemesi, 12.11.2015, E. 2015/32, K. 2015/102, pn. 7.

²⁷⁷ ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 109.

²⁷⁸ Ancak, işaret etmemiz gerekir ki, yeni TCK'da da, esasen haksızlık teşkil etmeyen ve dolayısıyla toplumsal düzen açısından herhangi bir değer ihlali niteliği taşımayan bazı fiiller “suç” olarak tanımlanmıştır (m. 263).

Yeni TCK'nın TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen metninin bazı maddelerine muhalefet eden Kilis Milletvekili Hasan KARA, bu maddeye ilişkin karşı oy yazısında şu açıklamalarda bulunmuştur:

«Eğitim ve öğretim faaliyeti, devlet eliyle yürütülebileceği gibi, kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak ve bu iznin koşulları çerçevesinde özel hukuk kişileri eliyle de yürütülebilir. Özel hukuk kişileri eliyle yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetinin devletin denetim ve kontrolü altında olması gerekir.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin özel hukuk kişileri eliyle yürütülebilmesini sağlamaya yönelik olarak yapılan düzenlemelerde öngörülmüş olan koşulların varlığı halinde, yürütülen faaliyetin hukuka aykırı bir yönünün bulunmayacağı aşıkardır.

Ancak, kimin, nerede, kime ve hangi konuda eğitim verdiğinin devlet tarafından bilinebilmesi için, bu faaliyetlerin önceden kamu makamlarının iznine tabi tutulması doğaldır. Buna rağmen, içerik itibarıyla hukuka aykırı herhangi bir hususun öğretilmediği bir eğitim ve öğretim kurumunun gerekli izinler alınmaksızın açılması, sadece idari yaptırım uygulanmasını gerektiren bir husustur. İçerik itibarıyla hukuka aykırı olmayan ve suç teşkil etmeyen hususları öğretmeye yönelik olarak yürütülen bir faaliyet, ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmez. Öğretilenlerin içerik itibarıyla suç oluşturmaları durumunda; olayın özelliğine göre, suça iştirak, suç işlemeye alenen tahrik ve hatta suç işlemek için örgüt kurma suçlarına ilişkin hükümlerin uygulanacağında kuşku bulunmamaktadır.

Halbuki, söz konusu suç tanımıyla, öğretilenlerin içerik itibarıyla herhangi bir suç oluşturmamasına rağmen, sadece gerekli izinler alınmadan bir öğretim faaliyetinde bulu-

nusu edilen kanun ile, ülkedeki anayasal düzen açısından teknik olarak *kanun* niteliği taşıyan yasama tasarrufları kastedilmektedir²⁷⁹.

Keza, *cezada kanunilik ilkesi* gereğince, kanunda suç olarak tanımlanan bir fiil dolayısıyla nasıl bir cezai yaptırım uygulanabileceği ve bunun miktarının ne kadar olabileceği hususları yine ancak kanunla belirlenebilir. İşaret etmek gerekir ki; Anayasa, bu prensibin bir ceza hukuku yaptırımı olan *güvenlik tedbirleri* açısından da geçerli olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir (m. 38, f. 3)²⁸⁰. Yeni TCK’nın 2. maddesinde de, Anayasanın bu hükmüne paralel düzenleme yapılmıştır.

Yeni TCK’nın düzenlemesine göre, “*Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükümlenemez.*” (m. 2, f. 1)

Madde **gerekçesinde** bu fıkra hükmüyle ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Kanunun amacına ilişkin maddesinde ifade edilen kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınabilmesi için, hangi fiillerin suç teşkil ettiğinin kanunda açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aynı şekilde, suç işlenmesi dolayısıyla verilecek ceza ve (güvenlik) tedbirler(iy)le, cezaya mahkûmiyetin hukuki sonuçları ve bu yaptırımların süre ve miktarlarının da kanunla düzenlenmesi zorunludur.

Anayasamızda da ifade edilen ve evrensel nitelikteki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin gereği olarak suçların tanımlanması ve ceza hukuku yaptırımları koyma yetkisine sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi sahiptir. Yine Anayasamıza göre yasama görevi, devredilmesi mümkün olmayan bir yetkidir. Bireyin maddi ve manevi varlığı üzerinde derin etkiler doğuran suç ve cezaların, ancak ulusal iradeyi temsil eden organ tarafından yapılacak kanunla düzenlenebilmesi, kişi hak ve özgürlüklerine sağlanan en önemli anayasal garantilerden birini oluşturmaktadır.”^{281,282}

nulması, suç haline getirilmektedir.» (TBMM Adalet Komisyonunun TCK Tasarısına ilişkin 3 Ağustos 2004 tarih ve Esas 1/593, Karar 60 sayılı Raporu ekindeki Karşı Oy Yazısı, in: TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı 664, sh. 247).

Nitekim bu mülahazalarla ki, söz konusu madde, bilahare **17.4.2013** tarihli ve 6460 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır (m. 13).

²⁷⁹ Bu itibarla, söz konusu ilke açısından yapılan “biçimsel kanunilik ilkesi”-“öze ilişkin kanunilik ilkesi” şeklindeki ayırımın (TOROSLU, sh. 14 vd.) isabetli olmadığını düşünmekteyiz.

²⁸⁰ Bkz. ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 105; ARTUK, Emin: *Ceza Hukukuna Giriş (Ders Notları)*, İstanbul, 1983, sh. 94.

²⁸¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 404 vd.

²⁸² Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 31.10.2008 gün ve 295/351 sayılı kararı ile, sanığı işlediği birden fazla ikna suretiyle irtikap suçundan dolayı, fiilin işlendiği tarih itibarıyla yürürlükte olan ve lehe hükümler içermesi dolayısıyla mülga 765 s. TCK hükümlerine göre toplam 7 yıl hapis

II. Suçta Kanunilik İlkesi ve “Beyaz Hüküm” Sorunu

Yukarıda ifade edildiği gibi, suçta kanunilik ilkesinin gereği olarak, suç teşkil eden fiilin bütün unsurlarının kanunla tanımlanmış olması gerekmektedir. Yani hangi fiillerin suç oluşturduğunun kanunda “açıkça” gösterilmiş olması gerekmektedir.

Ancak, ülkemiz mevzuatında bazı kanunlarda belli konularda düzenleme yapma hususunda çeşitli idari organlar, örneğin Bakanlar Kurulu, yetkili kılınmıştır. Yine aynı kanunlarda bu yetkilendirme çerçevesinde yapılan düzenlemelere aykırı davranışların suç oluşturacağı ve faillerinin cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Bu konuda bilinen örneği, **20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun** oluşturmaktaydı. Söz konusu Kanunun 1. maddesine göre;

“Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle tediyeyi temine yarıyan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması zımında kararlar ittihazına Cumhurbaşkanı salahiyetlidir.”^{283, 284}

Keza, aynı Kanunun 3. maddesinin 2008 yılında **5827 s. Kanunla yapılan değişiklikten önceki düzenlemesine** göre;

“a) Bakanlar Kurulunca l'inci maddeye göre alınan kararlara aykırı hareket eden veya bu kararlarda belirlenen yükümlülüklerini yerine getir-

cezasına mahkum eder. Mahkeme, mülga 765 s. TCK'nın 219. maddesi uyarınca sanığın “memuriyetten müebbeten mahrumiyetine ve memuriyetten ihracını gerektirir birden fazla ikna suretiyle irtikâp suçundan mahkûm olması ve ayrıca memuriyetten müebbeten mahrumiyet cezası ile cezalandırılması nedenine dayalı olarak, kararın kesinleşmesini müteakip 64.472.020.0 sicil numarası ile emekli olduğu görülmekle; **emekliliğinin sona erdirilmesi** amacıyla kararın bir örneğinin gereği için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar” vermiştir.

Bu kararın Yargıtay 5. CD tarafından 26.4.2010 tarih ve 960/3011 sayılı onanması üzerine, bu onama kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 14.4.2011 tarih ve 97319 sayılı ile itiraz edilmiştir.

İtiraz üzerine Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**, verdiği **21.6.2011** tarihli ve E. 2011/5-101, K. 2011/139 sayılı Kararı ile; suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, işlendiği sırada, kanunun açıkça suç saymadığı fiilden dolayı hiç kimseye ceza verilemeyeceği gibi, hiç kimse belli bir suçla ilgili olarak kanunda öngörülmemiş ceza veya güvenlik tedbiri veya kanunda öngörülenden daha fazla bir cezayla cezalandırılmayacağına işaret edildikten sonra; TCK'da ve sair kanunlarda bir suçtan dolayı cezaya “**mahkûmiyetin yasal sonucu olarak emekliliğinin sonlandırılması**”nı gerektiren bir yaptırıma yer verilmemiş olması sebebiyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu itirazını kabul etmiştir.

²⁸³ Bu yetki, daha önce **Bakanlar Kuruluna** ait iken, 2.7.2018 tarihli ve 700 sayılı KHK ile söz konusu Kanunda yapılan değişiklikle, **Cumhurbaşkanına** verilmiştir.

²⁸⁴ Bakanlar Kurulu'nca bu kapsamda çıkarılmış olan ve halen yürürlükte bulunan kararı, 25.10.1988 tarih ve 88/13431 sayılı “*Bedelsiz ithalata İlişkin Karar*”dır (RG.: 14.11.1988/19979 Mükerrer).

meyen gerçek ve tüzel kişiler ikimilyar liradan yirmibeşmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

...

b) Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını I'inci maddeye göre alınan kararlardaki hükümlere göre yurda getirmeyenler yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetin rayiç bedelinin yüzde beşi tutarında ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.”

Görüldüğü gibi, bu hükümlerde suç teşkil eden fiiller açıkça tanımlanmamıştı. Aksine, hangi davranışların suç oluşturacağı, Bakanlar Kurulunun alacağı kararlarla, yani idari işlemlerle belirlenmekte idi.

Bu tür hükümlere, “beyaz hüküm”²⁸⁵ veya “çerçeve kanun”²⁸⁶ denmektedir.

Aslında, bu şekildeki düzenlemeler ile suçta kanunilik ilkesi dolanılmaktadır²⁸⁷. 1567 s. Kanunun 2008 yılında 5827 s. Kanunla yapılan değişiklikten önceki düzenlemesi, suçta kanunilik ilkesinin ve dolayısıyla, Anayasanın 38. maddesi hükmünün ihlali mahiyeti taşımaktaydı^{288, 289}.

²⁸⁵ “Açık ceza normları” (TOROSLU, Ceza Hukuku, sh. 11); “Blankettnorm”. Ayrıntılı bilgi için bkz. İÇEL, Kayıhan/DONAY, Süheyl: *Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım*, 1. Kitap, 3. bası, İstanbul, 1999, sh. 58, 105 vd.; ARTUK, Ders Notları, sh. 97.

²⁸⁶ ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 121.

²⁸⁷ Bu tür düzenlemelerin suçta kanunilik ilkesine aykırılık oluşturduğu görüşü için bkz. İÇEL/DONAY(3) sh. 110 vd.; YARSUVAT, Duygun: *Yürütme Organının Koyduğu Kaidelerle Suç İhdası ve 1961 Anayasası*, İstanbul ÜHFM, cilt XXIX, sayı 3, İstanbul, 1963, sh. 555.

²⁸⁸ Aynı doğrultuda fikir için bkz. İÇEL/DONAY(3), sh. 110 vd.; İÇEL, Kayıhan: *Sermaye Piyasası Kurulunun Tebliğlerine Aykırılık Suçu*, İstanbul ÜHFM, Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’na Armağan Sayısı, cilt LVI, yıl 1998, sayı 1-4, sh. 113.

Aksi yöndeki görüş için bkz: DÖNMEZER/ERMAN I, no. 210; ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 124; GÖLCÜKLÜ, Feyyaz: “*İdari Ceza Hukuku*” ve *Anlamı, İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki*, in: SBFD, cilt XVIII, sayı 2, Ankara, 1963, sh. 123 vd.; TOSUN, Öztekin: *Yürütme Organlarının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması*, İstanbul ÜHFM, cilt XXVIII, sayı 2, İstanbul, 1962, sh. 351; YÜCE, Turhan Tüfan: *Ceza Hukuku Dersleri, cilt I, (Giriş, Genel Bilgiler, Ceza Hukukunun Yürürlüğü, Suç Teorisi)*, Manisa, 1982, sh. 61.

²⁸⁹ Ancak, işaret etmemiz gerekir ki; 1567 sayılı Kanunun bu düzenlemesinin iptali amacıyla açılan davada Anayasa Mahkemesi, bu şekildeki bir düzenlemenin Anayasaya aykırılık oluşturmadığı sonucuna ulaşmıştı (28.3.1963 t. ve 4/71 s. Karar [AMKD, sayı I, sh. 161 vd.]).

Anayasa Mahkemesine göre, «1567 sayılı Kanunun 3. maddesi ise; “İcra Vekilleri Heyetince” 1. maddeye istinaden itihaz edilen kararlara aykırı hareket edenlere ceza tayin etmiştir. Bu hükümle; suçun kanunî unsuru “İcra Vekilleri Heyetinin” 1. maddeye göre aldığı kararlara aykırı harekette bulunmaktır. Şu halde suçun ne olduğu kanunla belirtilmiştir.»

Anayasa Mahkemesi, aynı doğrultuda ikinci bir karar daha vermiştir:

“1567 sayılı Yasa’nın itiraz konusu kuralla göndermede bulunulan 1. maddesiyle yasakoyucu yürütmenin hangi alanı düzenleyeceğini saptamıştır. Bu da, kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve satımının ve bunlarla kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul ve-

Bu mülahazalarladır ki, 1567 s. Kanunun 3. maddesi, **24.12.2008 tarihli ve 5827 sayılı Kanunla** değiştirilerek²⁹⁰, “*Bakanlar Kurulunun bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklerle aykırı*”lık oluşturan fiiller, **suç olmaktan çıkarılmış** ve idari para cezasını gerektiren **kabahat** olarak tanımlanmıştır²⁹¹.

Ancak, belirtelim ki; Anayasanın suçta ve cezada kanunilik ilkesini düzenleyen 38. maddesinin gerekçesinde yer verilen şu ifadeler, Anayasayı yapan “İrade”nin ülkemizdeki uygulamayı “anayasallaştırmak gayreti”ni ortaya koymaktadır:

«... Bu hükme göre suç ve cezalar ve güvenlik tedbirleri ancak yasama tasarruflarıyla konulabilecektir. Keza, gene bu kural uyarınca, kanunun suç olarak öngörmediği ve ceza koymadığı bir fiil sebebiyle de kimse ce-

ya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle tediye sağılayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracını ve memlekete ithalini tanzim ve tahdit etmek ve Türk Parasının kıymetinin korunması zımında kararlar almaktır. Böylece, konuya ilişkin temel kurallar saptanmıştır.

Ekonominin kendi kuralları içinde yürütülecek ve bunun dışına çıkıldığında ülkeyi büyük malî zararlara uğratabilecek olan ve teknik konuları kapsamamasının yanısıra geciktirmeden zamanında önlemler alınması ve gerektiğinde derhal kaldırılması ve değiştirilmesi gereken bu alanın, yasakoyucu tarafından doğrudan doğruya düzenlenmesi kimi sakıncalar doğurabilir. Bu nedenledir ki, yasakoyucu düzenleme alanının esaslarını saptayarak amacı belirledikten sonra alınacak önlemlerin gereksinimlere uygunluğunu sağlamak üzere yürütme organını görevlendirmiş ve bu görevin gerektirdiği tasarruflarda bulunma yetkisini vermek suretiyle yasama yetkisini bu yolda kullanmayı uygun bulmuştur.

...

1567 sayılı Yasa'nın 3. maddesinin (a) bendinde, "Bakanlar Kurulu"na 1. maddeye dayanılarak alınan kararlara aykırı hareket edenler hakkında ceza yaptırımını öngörülmüştür. Buna göre, suçun yasal unsuru Bakanlar Kurulu'nun 1. maddeye göre aldığı kararlara aykırı davranmaktır. Bu nedenle, suçun yasallığı ilkesine aykırılık görülmemiştir.

Yasakoyucu tarafından suçun unsurlarının saptanmasından ve suç oluşturan eylemin ve cezanın yasada açıkça belirlenmesinden sonra ayrıntılarla uzmanlık ve yönetim tekniğine ilişkin konuların düzenlenmesinde yürütmeye yetki verilmesi, kararla suç oluşturma anlamına gelmez ve yasallık ilkesi de zedelenmez. Kaldı ki, Bakanlar Kurulu kararı daha önce Resmi Gazete'de yayımlanarak kişilere hangi eylemlerin yasaklandığı duyurulmakta ve böylece kişinin güvencesi sağlanmaktadır. Ceza da yasa ile gösterildiğine göre kararname ile suç oluşturulması söz konusu olamayacağından bu konuya ilişkin sav yerinde görülmemiştir.”: Anayasa Mahkemesi, 8.10.1998, E. 1997/53, K. 1998/62 (RG: 4 Temmuz 2001-24452).

1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, m. 3'de 24.12.2008 tarihli ve 5827 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki düzenlemesi itibarıyla “beyaz hüküm” mahiyeti taşıyan bu tanım, suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olduğu değerlendirildiği için, 5827 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve yapılan değişiklikle, bu fiiller suç olmaktan çıkarılıp, idari yaptırım gerektiren **kabahat** olarak nitelendirilmiştir.

²⁹⁰ RG: 30 Aralık 2008/27096.

²⁹¹ 1567 s. Kanunu değiştiren **24.12.2008 tarihli ve 5827 sayılı Kanuna** ilişkin Teklif metni tarafımdan kaleme alınmıştır. Söz konusu Kanun Teklifinin TBMM'deki görüşmeleri sırasında verilen bir önerge ile maddeye yedinci ve sekizinci fıkralar olarak eklenen hükümlerde özensizlik sonucu “**suç**” ibaresi kullanılmıştır.

zalandırılmayacaktır. Bu hüküm, kanun koyucunun, “açık suç hükmü” koymasına; yani “fiili” bildirmeden suç konusunu gösterip bunun müeyyidesini belirtmesine engel değildir. Meselâ Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkındaki Kanunun yaptığı gibi; bu gibi hallerde ne yasama yetkisi devredilmiş ne de “kanunsuz suç olmaz” ilkesi ihlâl edilmiştir.”²⁹²

Anayasanın **21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla** yapılan değişiklikten önceki **kanun hükmünde kararname** çıkarma yetkisini, söz konusu değişiklikten sonra ise **Cumhurbaşkanlığı kararnamesi** çıkarma yetkisini düzenleyen hükümleriyle bu görüşü telif etmenin mümkün olmadığını düşünmekteyiz²⁹³.

Anayasanın **21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla** yürürlükten kaldırılan 91. maddesine göre, *“Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak ... olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.”* (f. 1). Bu hükümler, kanun hükmünde kararnameler ile -“olağan” hukuk rejiminde- ancak *“Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler”* düzenleme yapılmasına imkan tanımaktaydı. Bu itibarla Anayasada, **kişi hak ve hürriyetleri üzerinde doğrudan bir etki doğurduğu için, KHK ile suç ihdasına imkân tanınmamıştır**²⁹⁴.

²⁹² Gerekçe için bkz. KUZU, Burhan: *Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat*, İstanbul, 1997, sh. 65.

²⁹³ Aynı doğrultuda fikir için bkz. İÇEL/DONAY(3), sh. 111; ARTUK, Ders Notları, sh. 112. Ancak, Önder, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini düzenleyen bu Anayasa hükmünün yürütmenin düzenleyici işlemlerle suç ihdasıyla çelişki arzemediği görüşündedir (ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 124).

²⁹⁴ Nitekim, Anayasa Mahkemesi, çeşitli kanun hükümlerini, Anayasanın suçta ve cezada kanunilik ilkesini güvence altına alan 38. maddesi hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle, iptal etmiştir:

“Anayasa hukukunun temel ilkelerinden birini oluşturan suç ve cezada yasallık ilkesi, özgürlük ve insan haklarının gelişerek bireyin öne çıktığı günümüzde, ceza hukukunun da temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Günümüzde bu ilkeye uluslararası hukukta ve insan hakları belgelerinde de yer verilmektedir.

Anayasanın 38. maddesine göre hangi eylemlerin suç sayılacağı ancak yasayla öngörülebilir. Anayasa'nın 7. ve 87. maddeleri gereğince yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olup bu yetki devredilemez. Anayasadaki açıklık karşısında yürütmenin suç oluşturabilmesi olanaklı değildir.

Anayasa'nın 91. maddesinde TBMM'nce Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verilebileceği öngörülmekte ve KHK ile düzenlenemeyecek konular sayılmaktadır. "Anayasa'nın suç ve cezalara ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 38. maddesi, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyecek yasak alan kapsamına girmektedir. Yürütme organının KHK ile suç oluşturmaya Anayasa'da izin verilmez iken düzenleme olanakları ve biçimleri KHK'lere göre çok daha kolay olan ve hukuk kuralları hiyerarşisinde daha sonra gelen idarî düzenlemelerle kimi eylemlerin suç sayılması açıklanan Anayasa kurallarına aykırı düşer.

Dayanağını Anayasa'nın 38. maddesinin oluşturduğu ve Türk Ceza Yasası'nın 1. maddesinde yer alan, "Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesinin esası, yasa tarafından, suçun, yani ne gibi eylemlerin yasaklandığının hiçbir şüpheye verilmeyecek biçimde belirtilmesinden ve buna göre cezanın

Ancak bu düzenleme, olağanüstü hal ilanı üzerine çıkarılan KHK'lerle "Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler"le ilgili olarak düzenleme yapılmasına imkan tanımaktadır. Buna göre, **olağanüstü hal KHK'leri ile, olağanüstü hal ilanına sebebiyet veren olaylar bağlamında kişilere özel birtakım yükümlülükler yüklenebilir ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, suç veya kabahat olarak tanımlanabilir.** Ancak önemle belirtmek gerekir ki, **olağanüstü hal KHK'leri ile, ancak olağanüstü hal rejiminin uygulandığı yerlerde ve olağanüstü hal süresince işlenen fiillere özgü olarak suç veya kabahat tanımı yapılabilir ve ceza konulabilir.** Olağanüstü hal süresince işlenen belirli fiillere ilişkin suç veya kabahat tanımları, ancak, olağanüstü hal rejiminin uygulandığı yerlerde ve olağanüstü hal süresince işlenen fiillerle ilgili olarak uygulanabilir. Fiil, olağanüstü hal döneminde işlenmiş ise, bilahare olağanüstü hal kaldırılmış olsa bile, suç veya kabahat oluşturmaya devam eder ve faili bu sebeple cezalandırılır (TCK, m. 7, f. 4)²⁹⁵.

yasayla belirlenmesinden ibarettir. Kişinin, yasak eylemleri ve bunların cezalarını önceden bilmesi gerekir. Bu durum, kişinin temel hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Bu nedenle de Anayasa'nın kişinin temel hak ve ödevlerine ilişkin bulunan ikinci bölümünde bu güvenceye yer verilmiştir.

Tüm bunlar suç ve cezaların yalnızca yasayla konulup kaldırılmasının yeterli olmadığı, konulan kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belirli olması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. ... yasanın herkesçe anlaşılacak ölçüde açık olması da bunun doğal sonucudur. Nitekim, Türk Ceza Yasası'nın 1. maddesinde "kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez" denilerek bu husus vurgulanmıştır.

...

Cezanın yasallığı ilkesi, bir suça uygulanacak yaptırım türlerinin, ölçülerinin, hangi sınırlar içinde uygulanacağını, nelerin ne ölçüde hafifletici veya ağırlaştırıcı neden olacağını Yasakoyucu tarafından kurala bağlanmasını zorunlu kılmaktadır.

(Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenen madde metninde, suçun karşılığında) verilecek cezaların türü ve miktarı açıkça belirlenmiştir. Bu nedenle fıkranın "cezanın yasallığı" yönünden Anayasa'nın 38. maddesine aykırılığı savı yerinde değildir.

(Ancak) Bakanlar Kurulu'nca bir malın ithal veya ihracının yasaklanması ile eylem suç oluşturmaktadır. Böylece itiraz konusu kuralla suç belirlenmemekte, suç olma niteliği bu kuralla Bakanlar Kurulu kararına bırakılmaktadır. Bu ise Anayasa'nın 38. maddesinde öngörülen "suçun yasallığı" ilkesine aykırıdır.

...

İthal ve ihracı yasaklama yetkisine sahip olan Bakanlar Kurulu bu yolla eylemin suç sayılıp sayılmayacağını belirlemiş olmaktadır.": 27.9.1994, E. 1993/42, K. 1994/72 (RG: 22 Eylül 1995/22412); 6.7.1993, E. 1993/5, K. 1993/25 (RG: 25 Şubat 1995/22213).

²⁹⁵ Oysa Cumhurbaşkanının başkanlığında 15.8.2017 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında (694 sayılı) Kanun Hükmünde Kararname" ile Türk Ceza Kanununun, 188, 190 ve 228. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik,

a) 188 maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında tanımlanan suçların yaptırımı olarak hapis cezasının yanında adli para cezasına alt sınır getirilmiştir (m. 137);

Anayasanın 91. maddesi, 6771 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği ile, Türk hukukundaki normlar hiyerarşisinde **Cumhurbaşkanlığı kararnamesi** ihdas edilmiştir (Any, m. 104, f. 17).

Önemle belirtmemiz gerekir ki, **91. madde yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, bu madde hükmüne istinaden daha önce çıkarılmış olan olağan veya olağanüstü hallere ilişkin KHK'ler**, bilahare yürürlükten kaldırılmadıkları takdirde, **hukuki varlığını devam ettirmektedir**.

Anayasanın 6771 sayılı Kanunla değiştirilen 104. maddesine göre;

“Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.” (f. 17).

Keza, Anayasanın 6771 sayılı Kanunla değiştirilen 119. maddesine göre;

“Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.”

Bu itibarla, 6771 sayılı Kanunla değişik Anayasa, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle *“Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler”*le ilgili olarak da düzenleme yapılmasına imkan vermektedir. Ancak, **olağanüstü ha-**

b) 190. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan suçların karşılığında yaptırım olarak hapis cezasının yanında adli para cezası getirilmiştir (m. 138);

c) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ile ilgili olarak iki ayrı nitelikli hal ihdas edilmiş ve bu çerçevede 228. maddeye üçüncü ve dördüncü fıkralar olarak yeni fıkralar eklenmiştir (m. 139).

Bu düzenlemelerin olağanüstü halle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu düzenlemeler, olağanüstü hale özgü değildir. **Anayasaya aykırı** olarak yapılan bu düzenlemelerde bir **yetki gaspı** söz konusudur.

Ancak belirtmek gerekir ki, söz konusu KHK bilahare 1.2.2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunla (RG: 8 Mart 2018/30354 Mükerrer) kanunlaştırılmıştır. Böylece TCK'da yapılan söz konusu değişiklikler bağlamındaki Anayasaya aykırılık giderilmiştir.

lin gerekli kıldığı konularda çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, “kanun hükmünde” olsa bile (Any, m. 119, f. 6, ikinci cümle), suç ve kabahat ihdas edilemez ve ceza konulamaz. Zira, “*Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.*” (Any, m. 104, f. 17, üçüncü cümle). Anayasanın 36. maddesine göre, “*Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.*” (f. 3).

Yine işaret etmek gerekir ki, “*Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.*” (Any, m. 104, f. 17, dördüncü cümle). Keza Anayasaya göre, “*Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.*” (m. 142, f. 1). Bu düzenlemeler karşısında, kanaatimizce, yürürlükteki kanunlarda yer alan soruşturma ve kovuşturmayla, keza ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hükümlerde, olağanüstü hale özgü de olsa, istisnaî mahiyette, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılamaz.

Yeni TCK’da, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin evrensel hukuktaki anlaşılış biçimine uygun olarak düzenleme yapılmıştır. Buna göre; “*İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç (ihdas edilemez) ve ceza konulamaz.*” (m. 2, f. 2).

Madde gerekçesinde bu kurala ilişkin olarak yer verilen açıklamalar, uygulamadaki tereddütleri giderebilecek açıklıktadır²⁹⁶:

«Anayasamızda da ifade edilen ve evrensel nitelikteki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin gereği olarak suçların tanımlanması ve ceza hukuku yaptırımları koyma yetkisine sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi sahiptir. Yine Anayasamıza göre yasama görevi, devredilmesi mümkün olmayan bir yetkidir. Bireyin maddi ve manevi varlığı üzerinde derin etkiler doğuran suç ve cezaların, ancak ulusal iradeyi temsil eden organ tarafından yapılacak kanunla düzenlenebilmesi, kişi hak ve özgürlüklerine sağlanan en önemli anayasal garantilerden birini oluşturmaktadır.

Anayasada temel hak ve özgürlükler alanının, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceğinin öngörülmesi de, bu garantinin bir ifadesidir. Kişi hak ve özgürlükleri konusunda kanun hükmünde kararname çıkarılmaması bakımından anayasal normla getirilen bu yasağın, idarenin diğer düzenleyici işlemleri için de geçerli olduğu kuşkusuzdur. İşte maddenin ikinci fıkrasındaki düzenlemeyle, Anayasada yer alan emredici normların gereği yerine getirilerek, idarenin düzenleyici işlemleriyle bir suç tanımının kapsamının belirlenemeyeceği ve ceza konulamayacağı açıkça düzenlenmiş olmaktadır.»

Ancak, belirtmemiz gerekir ki; suçta kanunilik ilkesine bu Kanunda yer alan bazı suç tanımlarında riayet edilmemiştir. Örneğin, 297. maddenin ikinci fıkrasında

²⁹⁶ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 404 vd.

“yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan eşyayı” infaz kurumuna veya tutukevine sokmak, bulundurmak veya kullanmak suç olarak tanımlanmıştı. Dikkat edilmelidir ki, bu düzenlemede suçun konusu, doğrudan kanunla belirlenmiş değildi. Suç konusu eşyayı belirleme hususunda idari makamlar yetkili kılınmıştı²⁹⁷. Söz konusu maddenin TBMM Adalet Alt Komisyonundaki müzakereleri sırasında bu hususa işaret etmemize rağmen, kaygılarımız dikkate alınmamıştı. Fakat, madde metnine hiç olmazsa “*bu yasağı bilerek*” ibaresini koydurarak, bu suçun ancak doğrudan kastla işlenebilmesine yönelik bir sınırlama yapılmasını başarmıştık. Belirtilen mülahazalarla, söz konusu fıkra hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından, suçta kanunilik ilkesini ihlal ettiği ve bu sebeple Anayasanın 38. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle **iptal** edilmiştir²⁹⁸.

Keza, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı *Bankacılık Kanununun “Düzeltilici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak”* başlıklı 152’nci maddesinde suçta kanunilik ilkesiyle bağdaşmayan ve Anayasanın 38’inci maddesine aykırı suç tanımına yer verilmiştir:

“Bu Kanunun 68, 69 ve 70’inci maddelerine ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14’üncü maddesine göre, Kurul veya Kurumca alınması istenen önlemleri almayan bankaların bu önlemleri almakla yükümlü olan mensupları, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Birinci fıkrada belirtilen önlemleri almamak, bankanın nitelikli paya sahip ortaklarına veya bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla yapıldığı takdirde dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasına ve onbin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.”

²⁹⁷ Aynı durum, 174’üncü maddenin birinci fıkrası ile 193’üncü maddede tanımlanan suçlar bakımından da söz konusudur.

²⁹⁸ Anayasa Mahkemesinin 7.7.2011 tarihli ve E. 2010/69, K. 2011/116 sayılı Kararı (RG: **21 Ekim 2011/28091**).

Ancak, Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararında önemli bir **çelişkiye** düşülmüştür. Yüksek Mahkeme, **söz konusu iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceğine karar vermiştir. Bu, önemli bir çelişkidir. Suçta kanunilik ilkesinin ihlal edildiği bir hükmün uygulanmasına belirli bir süre de olsa izin verilmesi doğru olmamıştır. Aslında, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlali suretiyle yapılan bir kanuni düzenleme iptal edildiğinde, bu iptal kararının ileri bir tarihte yürürlüğe gireceği yönünde karar verilmiş olsa bile, artık iptal edilmiş olan bu hükme istinaden bir mahkûmiyet hükmü tesis edilemez ve hatta, bu hükme istinaden daha önce verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükümleri dahi hükümsüz hale gelir. İptal edilmiş olan hükmün yerine suçta ve cezada kanunilik ilkesine uygun yeni bir kanuni düzenleme yapılmış olsa bile, bu durum değişmez. Zira bu ihtimalde, suçta ve cezada kanunilik ilkesine uygun olan kanun hükmü ancak, yürürlüğe girdikten sonra işlenen fiillerle ilgili olarak uygulama kabiliyeti bulur.** İşaret etmemiz gerekir ki, Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı üzerine TCK’nın 297. maddesinin ikinci fıkrası, 24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir (m. 20). Bu düzenleme de suçta kanunilik ve belirlilik ilkeleri bakımından sorunludur.

Söz konusu Kanunun “*Düzeltilici önlemler*” başlıklı 68’inci maddesine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu maddede belirlenen tedbirlerden “*bir veya birkaçının ya da tamamının ve Kurumca uygun görülecek diğer tedbirlerin, Kurumun uygun göreceği bir süre ve onaylayacağı bir plân dâhilinde alınmasını ve uygulanmasını bankanın yönetim kurulundan ister.*” Dikkat edilmelidir ki, bu tedbirler, 68’inci maddede tadadi olarak gösterilmemiştir. Bu tedbirler, genel düzenleyici işlemle de belirlenmemektedir. Bu tedbirler, ilgili bankanın içinde bulunduğu şartlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Kurum başkanı veya diğer görevlileri tarafından belirlenmektedir. Başka bir deyişle, bu tedbirlerin belirlenmesi hususunda Kurumun karar organı olan Kurul da, münhasıran yetkili kılınmamıştır.

Keza aynı Kanunun “*İyileştirici önlemler*” başlıklı 69’uncu maddesine göre; Kurul, bu maddede belirlenen tedbirlerden başka “*uygun göreceği her türlü tedbirin, onaylayacağı bir plân çerçevesinde alınmasını ve uygulanmasını bankadan ister.*” Aynı şekilde Kanunun “*Kısıtlayıcı önlemler*” başlıklı 70’inci maddesine göre; Kurul, bankadan bu maddede belirlenen tedbirlerden “*bir ya da birkaçının veya uygun göreceği diğer tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını ister.*” Bu maddelerde de, ilgili banka hakkında uygulanabilecek tedbirler tadadi olarak gösterilmemiştir. Her ne kadar bu maddeler kapsamında ilgili banka hakkında uygulanabilecek tedbirleri belirleme hususunda Kurul yetkili kılınmış ise de; bu tedbirlerin neler olabileceği genel bir düzenleyici işlemle değil, bir banka ile ilgili *birel işlem* kapsamında belirlenmektedir.

Bu yönü itibarıyla, Bankacılık Kanununda yer alan söz konusu suç tanımının (m. 152), **Anayasanın suçta kanunilik ilkesini de güvence altına alan 38’inci maddesine aykırı olduğu** kanaatindeyiz.

Sonuç olarak itiraf etmemiz gerekir ki; **Anayasada, normlar hiyerarşisinde kanundan önce temel kanun kategorisine yer verilmediği için, yeni TCK’nın 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ile 5’inci maddesi hükümlerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren çıkarılan ve çıkarılacak olan kanunlar bakımından mevzuat disiplini sağlama yönünden bir etkisi olamayacaktır.**

III. Belirlilik ilkesi²⁹⁹

Ceza hukukunun güvence fonksiyonunu icra edebilmesi açısından, suçta kanunilik ilkesinin benimsenmesi yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda, kanunda yer alan *suç tanımlarının açık ve seçik olması* gerekir. Yani, hangi insan davranışlarının suç oluşturduğunun kanun metninden açık bir şekilde anlaşılabilir olması gerekmektedir. Hangi insan davranışlarının suç teşkil ettiğini belirleyen kanun metinlerinin çok

²⁹⁹ “Bestimmtheitsgrundsatz”.

açık ve herkes tarafından anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesi lazımdır³⁰⁰. Bu husus, yeni TCK'nın 2. maddesinde “*Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz.*” şeklinde ifade edilmiştir.

Bu bakımdan, belirli bir kanuna yollamada bulunmak suretiyle soyut olarak bu kanuna aykırı davranışların ceza yaptırımına bağlanması, suçta kanunilik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Suç tanımlarının redaksiyonunda, bu ilkeye bağlı kalmaya büyük bir özen gösterilmiştir. Örneğin, yeni TCK'ya ilişkin Hükûmet Tasarısında, 765 s. Kanunda olduğu gibi, dolanlı (hileli) ve taksirli iflas suçlarının sadece yaptırımı belirlenmişti (m. 224). Buna karşılık, hangi fiil ve davranışların bu suçları oluşturacağı konusunda, herhangi bir belirleme yapılmamıştı. Bu konuda, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı *İcra ve İflâs Kanununun* 310 ve 311. maddelerinde yapılan düzenlemelere yollamada bulunulmuştu. Yeni TCK'da, ceza hukukunun güvence fonksiyonlarından birini oluşturan belirlilik ilkesinin gereği olarak, hileli ve taksirli iflas suçlarını hangi fiil ve davranışların oluşturduğu, açık ve seçik bir şekilde belirlenmiştir (m. 161, 162)³⁰¹. Keza, yeni TCK'ya ilişkin Hükûmet Tasarısında, 765 s. Kanunda olduğu gibi, ihaleye fesat karıştırma suçunu hangi fiil ve davranışların oluşturduğu belirli değildi. Belirlilik ilkesinin gereği olarak, ihaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma suçlarının tanımında açık seçiklik ilkesine özen gösterilmiştir (m. 235, 236)³⁰².

Belirlilik ilkesi, Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararlarında şu şekilde açıklanmıştır:

*“Hukuk devletin temel unsurlarından biri de belirlilik ilkesidir. Bu ilkeye göre yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuyla yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfî uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup kişinin kanundan belirli bir kesinlik içinde hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini verdiğini bilmesini zorunlu kılmaktadır. Kişi ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlayabilir. Hukuki güvenlik ilkesi bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.”*³⁰³

³⁰⁰ İÇEL/DONAY(3), sh. 54, 73, 83 dn. 56; EREM, Faruk/DANIŞMAN, Ahmet/ARTUK, Mehmet Emin: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. bası, Ankara, 1997, sh. 95, 99.

³⁰¹ TBMM Adalet Komisyonunun TCK Tasarısına ilişkin 3 Ağustos 2004 tarih ve Esas 1/593, Karar 60 sayılı Raporu, in: TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı 664, sh. 227.

³⁰² Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, sh. 227 vd.

³⁰³ Anayasa Mahkemesi, 29.4.2021, E. 2020/80, K. 2021/34 (RG: 22 Haziran 2021-31519), pn. 25; Anayasa Mahkemesi, 25.1.2023, E. 2022/133, K. 2023/15 (RG: 6 Nisan 2023-32155), pn. 10.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararlarında gerekçe olarak yer verilen açıklamalar, yasama organının ceza hukuku alanında yapacağı düzenlemeler bakımından yol göstericilik özelliği taşımaktadır³⁰⁴.

TCK'da çeşitli suç tanımlarında bir seçimlik hareket olarak, "*hukuka aykırı başka bir davranış*"³⁰⁵ ibaresine yer verilmiştir. Bununla neyin anlatılmak istendiğini her suç tanımı bakımından ayrı ayrı ele alıp değerlendirmek ve belirlemek gerekir.

Örneğin "*Eğitim ve öğretimin engellenmesi*" suçu (TCK, m. 112), cebir veya tehdit kullanılarak işlenebileceği gibi, kişilere karşı cebir veya tehdit uygulanmadan, örneğin binanın kapılarının kilitlenmesi suretiyle ya da gerçeğe aykırı bir şekilde sınavın iptal edildiğinin beyanıyla, yani hileli davranışlarla da işlenebilir. Söz konusu suçun cebir veya tehdit kullanma dışında başka suretlerle de işlenebileceği gerçeği karşısında, bütün bu ihtimaller bağlamında fiilin **hukuka aykırılık** özelliğine vurgu yapılmıştır. Bu vurgu, aynı zamanda söz konusu suçun ancak doğrudan kastla işlenebileceğine işaret etmektedir.

Keza, örneğin "*Kişilerin huzur ve sükununu bozma*" suçu (TCK, m. 123), tanımında açıkça belirtilen telefon etmek ve gürültü yapmak fiilleriyle işlenebileceği gibi, yüksek şiddette ışığa maruz bırakılmak suretiyle de kişinin huzur ve sükunu bozulabilir. Suç tanımında belirli seçimlik hareketler sayıldıktan sonra ayrıca "*hukuka aykırı başka bir davranış*" ibaresine yer verilerek, kişinin huzur ve sükununu bozmak maksadıyla gerçekleştirilmesine rağmen, sayılan seçimlik hareketler içinde yer almayan diğer muhtemel fiillerin yaptırımsız kalmasının önüne geçilmek amaçlanmıştır.

Nitekim Anayasa Mahkemesi, TCK'nın 123. maddesinde yer alan "*ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması*" ibaresinin belirlilik

³⁰⁴ Ancak, belirtmek gerekir ki, yeni TCK'da da bu ilkeyle bağdaşmayan suç tanımlarına yer verilmişti (m. 222). Yeni TCK'nın TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen metnin bazı maddelerine muhalefet eden Kilis Milletvekili Hasan KARA imzasını taşıyan karşı oy yazısında bu maddeye ilişkin olarak şu açıklamalarda bulunulmuştur:

«Madde metninde çeşitli kanun adları belirtilmek suretiyle, bu kanunların içeriğine genel mahiyette bir yollamada bulunulmaktadır. Bu şekildeki soyut suç tanımları, Anayasamızda ve Tasarının üçüncü maddesinde güvence altına alınan suçta kanunilik ilkesi ve özellikle belirlilik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Nitekim, bu husus, Adalet Komisyonu Raporunun IV numaralı paragrafında açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Ayrıca, Hükümet Tasarısının 302'nci maddesinin gerekçesinde de açıkça belirtildiği gibi, söz konusu Kanunlarda öngörülen yükümlülöklere belirli suretteki aykırı davranışların yine bu Kanunlar kapsamında özel olarak yaptırım altına alınması daha yerinde olacaktır.» (TBMM Adalet Komisyonunun TCK Tasarısına ilişkin 3 Ağustos 2004 tarih ve Esas 1/593, Karar 60 sayılı Raporu ekindeki Karşı Oy Yazısı, in: TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı 664, sh. 244).

Nitekim, söz konusu madde, 2.3.2014 tarihli ve 6529 sayılı Kanunla **yürürlükten kaldırılmıştır** (m. 16).

³⁰⁵ TCK, m. 112, 113, 114 [f. 2], 115 [f. 2], 117 [f. 1], 118 [f. 2], , 123, 223 [f. 1, 3], 224, [f. 1].

ilkesi bağlamında suçta kanunilik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla iptali talebini reddetmiştir.³⁰⁶

Bu arada önemle belirtmek gerekir ki, Anayasaya aykırılık itirazında belirtildiğinin aksine, hukuka aykırılık, izafi değildir; kişiye, yere ve zamana göre değişkenlik arz etmez.

IV. Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı

Medeni hukuk uygulamasında kanunda bulunan boşlukları doldurma, bu boşluklarla ilgili olarak hukuk kuralı koyma hususunda hakime yetki verilmiştir (MK, m. 1, f. 2)³⁰⁷. Buna karşılık, ceza hukukunda hakime kanunda bulunan boşlukları doldurma yetkisi, kanunu tamamlama görevi verilmemiştir.

Ceza hukukunda yorum kabul edilmekle birlikte, kişi hak ve hürriyetlerinin keyfi tasarruflara karşı güvence altına alınabilmesi için³⁰⁸, kıyas yöntemine başvurulamamaktadır.

A. Yorum

Yorum, bir kanun hükmünün anlamını, kanun koyucunun gerçek iradesini ortaya çıkarmaya yönelik bir fikrî faaliyettir.

TBMM Adalet Komisyonunun TCK Tasarısına ilişkin 3 Ağustos 2004 tarihli ve Esas 1/593, Karar 60 sayılı **Raporunda**; madde metnlerinin yorumu açısından önemli bir kurala yer verilmiştir³⁰⁹:

“Tasarıda yer alan her bir madde kapsamında madde başlığı, madde metni ve madde gerekçesine yer verilmiştir. Madde başlığı ve gerekçesi, madde metninin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Bu husus, madde hükümlerinin yorumlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır.”

Söz konusu Raporda yer alan “madde başlığı ve gerekçesi, madde metninin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır” şeklindeki ifade, madde başlığı ve gerekçesinin, madde metnine dahil olduğu şekilde anlaşılmamak gerekir. Aksine, söz konusu Raporda, **madde başlığı ve gerekçesinin** “*madde hükümlerinin yorumlanması açısından büyük bir önem taşı*”dığından söz edilerek, bunların bir **yorum aracı** olduğu vurgulanmıştır. Madde gerekçesi, maddede yer alan hükümle ilgili olarak hazırlık çalışmaları sırasında yapılan tartışmaların, ileri sürülen görüşlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır³¹⁰.

³⁰⁶ Any. Mahk., **7.9.2016**, E. 2016/44, K. 2016/153 (RG: 11 Ekim 2016/ 29854).

³⁰⁷ Ayrıntılı bilgi için bkz. İMRE, Zahit: *Medeni Hukuka Giriş (Temel Kavramlar, Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri ve Hakiki Şahıslar Hukuku)*, 3. bası, İstanbul, 1980, sh. 186 vd.

³⁰⁸ ARTUK, Ders Notları, sh. 105.

³⁰⁹ TBMM Adalet Komisyonunun TCK Tasarısına ilişkin 3 Ağustos 2004 tarih ve Esas 1/593, Karar 60 sayılı Raporu, in: TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı 664, sh. 226.

³¹⁰ Özbek, yeni TCK’nın madde metni ve gerekçeleri arasındaki ilişki bakımından şu tespit ve değerlendirmede bulunmaktadır: “Yasanın bütünü incelendiğinde çarpıcı bir başka sonuç ise bazen

Yukarıda da belirtildiği gibi, yorum, bir pozitif hukuk metni olan kanunun anlam ve kapsamını belirlemek amacı ile, **kanun koyucunun iradesinin ne olduğunu anlamak için**, yapılan fikrî faaliyettir³¹¹. Başka bir deyişle, yorum, bir iradenin ortaya çıkarılması çabasıdır.

Bir kanun hükmünün yorumlanmasında ilk başvurulacak araç, o hükmün lâfzıdır³¹². Bu yorum, kanun hükmünde yer alan kelimelerin anlamının tespiti ve gramer kurallarının uygulanması suretiyle yapılmaktadır³¹³ (*Lafzi yorum*).

Lafzi yorum, bir kanun hükmünün anlam ve kapsamının tam olarak anlaşılmasına her zaman yetmemektedir. Bu itibarla, bir kanun hükmünün anlam ve kapsamının doğru olarak anlaşılabilmesi için, ayrıca;

- a) kanunun hazırlık çalışmalarından,
 - b) kanunun sistematüğinden,
 - c) kanunla düzenlenen hukuki müessesenin tarihçesinden,
 - d) kanunla düzenlenen müesseseye ilişkin mukayeseli hukuktaki düzenlemelerden ve
 - e) hukukun genel ilkelerinden,
- yararlanmak gerekir.

Bir kanun maddesinde yer alan hükümle ilgili olarak hazırlık çalışmaları sırasında yapılan tartışmalar, ileri sürülen görüşler sonucunda ortaya çıkan **madde gerekçesinin**, kanun hükmünün anlam ve kapsamının tam olarak anlaşılmasına katkıda bulunan önemli bir **yorum aracı** olduğunda kuşku yoktur. Ancak, belirtmek gerekir ki, madde gerekçesi bir hüküm değildir. Bu itibarla, özellikle yeni TCK'nın kabulünden sonra, madde gerekçesinin bağlayıcı olup olmadığı yönünde yapılan tartışmaların hukuk bilimiyle telifi kabil bir yönü bulunmamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yeni TCK Tasarısına ilişkin hazırlık çalışmaları kapsamında TBMM Adalet Alt Komisyonunda yapılan müzakereler kayda alınmamıştır. Buna karşılık, TBMM Adalet Komisyonunda Tasarının geneli ve maddeleri üzerinde yapılan müzakereler ise, kayda alınmış ve yayımlanmıştır³¹⁴.

gerekçelerin asıl hükümlerden daha anlaşılır ve anlamlı olmasıdır. Unutulmamalıdır ki, gerekçe sadece o hükmün uygulanması sırasında **yorum** bakımından işlevsel bir nitelik taşımaktadır.": ÖZBEK, Veli Özer: *TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı (Açıklamalı-Gerekçeli-İctihatlı)*, Cilt I, Genel Hükümler (Madde 1-75), 2. bası, Ankara 2005, sh. 30.

³¹¹ Çeşitli yorum tanımları için bkz. DÖNMEZER Sulhi/ERMAN Sahir: *Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku*, cilt 1, İstanbul 1997, no. 254; EREM Faruk: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler*, cilt I, Ankara, 1973, sh. 87; TOSUN Öztekin: *Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri*, cilt 1, İstanbul 1981, sh. 95; ÇETİN, Soner Hamza: *Türk Ceza Hukukunda Yorum ve Kıyas*, Ankara, 2014.

³¹² EREM, sh. 101.

³¹³ TOSUN, sh. 111.

³¹⁴ **Tutanaklarla Türk Ceza Kanunu**, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Ankara, Şubat 2005; Güney, Niyazi/Özdemir, Kenan/Balo, Yusuf Solmaz: **Gerekçe ve Tutanak-**

Keza yeni TCK’da yer verilen “*Ceza Kanununun amacı*” başlıklı 1. maddesi ile “*Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi*” başlıklı 3. maddesi hükümleri, başlı başına uygulama kabiliyeti olmayan ve fakat, doğrudan uygulamaya yönelik diğer hükümlerinin uygulanmasında bir **yorum aracı** olarak telakki edilmelidirler.

B. Kıyas Yasağı

Yorum sınırlarını aşan *kıyas* ise, kanunda açık bir şekilde suç olarak tanımlanmamış olan bir fiilin, bununla bazı yönlerden benzerlik arzeden başka bir fiil ile ilgili suç tanımı kapsamında değerlendirilmesidir.

Yeni TCK’nın 2. maddesinin üçüncü fıkrası ile, ceza hukukunda kıyas yasağının kanuni dayanağı oluşturulmuştur³¹⁵. Buna göre;

«*Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.*»

Madde metninin bu hükme ilişkin **gerekçesi** yeterli açıklıktadır³¹⁶:

«*... suçta ve cezada kanunilik ilkesinin doğal bir sonucu olan evrensel ilke niteliğindeki ceza kanunlarının uygulanmasında kıyasa başvurulamayacağı, maddenin üçüncü fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. Böylece ceza kanunlarının bireye güvence sağlama işlevinin bir gereği daha yerine getirilmiş olmaktadır. Yeni tarihli ceza kanunlarında da kıyas yasağına ilişkin olarak açık hükümlere yer verilmektedir. Örneğin yeni Fransız Ceza Kanununda bu husus “ceza kanunları dar yorumlanır” biçiminde ifade edilmiştir. Kıyas yasağıyla getirilen güvencenin tam anlamıyla uygulanabilmesini mümkün kılmak amacıyla, kıyasa yol açacak şekilde yapılacak geniş yoruma da başvurulamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak bu hükümle ceza hukukunda genişletici yorum tümüyle yasaklanmamakta, sadece bu yorum biçiminin kıyasa yol açacak şekilde uygulanmasının önüne geçilmek istenmektedir.*»³¹⁷

larla Karşılaştırmalı Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara, Kasım 2004; Yılmaz, Zekeriya: **Gerekçe ve Tutanaklarla Yeni Türk Ceza Kanunu**, Ankara, 2004.

³¹⁵ Bu hükme yönelik tutarsız eleştiri için bkz. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş(4) sh. 54, 94, 95. Hafizoğulları da, Türk ceza hukuku uygulamasında kıyasla ilgili olarak tanık olunan içtihatları göz ardı ederek, söz konusu hükmü eleştirmektedir: “... ‘kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanama’ ifadesi yorumla kıyas arasında bir geçitlilik ilişkisinin bulunduğunu çağırıştırılmaktadır. Oysa, ister daraltıcı, ister genişletici, isterse ilerletici yorum söz konusu olsun, yorumla kıyas arasında bir geçitlilik ilişkisi yoktur. Ör., nasıl elma elma armut da armutsa, yorum yorum kıyas da kıyastır. Kıyas, kanunda hüküm bulunmayan hallerde, hukuka kaynaklık yapmaktadır. Yorum, mevcut bir normun anlamını bulup ortaya çıkarmak, kapsamını ve sınırlarını belirlemektir. İkisi arasında hiçbir geçitlilik ilişkisi bulunmamaktadır. Böyle olunca “kıyasa yol açacak yorum” diye ara bir şeyin mevcut olması mantıksal olarak imkansız olmaktadır.” (HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 21, dipnot 5).

³¹⁶ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 404 vd.

³¹⁷ Kıyas yasağı ile ilgili açıklamalar için bkz. BAKICI, Sedat: 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Ankara, 2007, sh. 17 vd.

Esasen haksızlık teşkil eden bazı fiillerin suç olarak tanımlanması konusunda ceza kanunlarında boşluklar olabileceği, kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak, bu gerçeğe rağmen, kıyas yoluyla suç ihdası kabul edilmemiştir. Somut olayda rahatsız edici sonuçlar ortaya çıkarsa bile, kanunda açıkça suç olarak tanımlanmayan bir fiilden dolayı bir kişiyi cezalandırmamak gerekir. Aksi uygulama, hukuk güvenliğiyle bağdaşmaz.

İşaret etmek gerekir ki, **kıyas yasağı, kanunda yer alan suç tanımlarının kapsamı açısından kabul edilmiştir**. Bu itibarla, ceza hukukunun genel hükümleri açısından, yani suç teorisinin genel prensipleri açısından kıyas yasağından söz edilemez³¹⁸. Suç vakıasını ve sorumluluğun esasını açıklayan bu prensipler açısından, kıyastan ziyade, genişletici yorumdan söz edilebilir. Bu itibarla, örneğin **TCK'nın zorunluluk haline ilişkin hükümlerinin uygulama alanını mümkün olduğunca geniş tutmak gerekir**^{319,320,321}.

Belgede sahtecilik suçunun konusunu oluşturan belgenin bir unsuru, **hukuki sonuç doğurabilecek içeriğe sahip** olmasıdır. Bu itibarla belge, **bir irade beyanını** ya da **mevcut bir durumu tespit** eden içeriğe sahiptir. Belge, belli bir duruma ilişkin olarak **değerlendirme** içeriğine de sahip olabilir.

Belgenin diğer bir unsuru, içerdiği irade beyanının, durum tespitinin veya değerlendirmenin belirli bir **kişiye izafe** edilmesi ya da edilebilir olmasıdır. Belirli bir kişiye izafe edilmeyen veya edilebilir olmayan içerik, belge hüviyetini haiz değildir.

Elektronik ortamdaki veriler, hukuki sonuç doğurmaya elverişli, hukuki değer ifade eden bir irade beyanını, durum tespitini veya değerlendirmeyi içerse ve hatta bu veriler belli bir kişiye izafe edilse bile; başlı başına bu özellikler, elekt-

³¹⁸ Aynı fikir için bkz. ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 129. Aksi yönde fikir için bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler (10), sh. 65; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, Genel Hükümler (13), sh. 160 vd.

³¹⁹ Zorunluluk haline ilişkin örnek kararlar için bkz. aşağıda sh. ... dn.

³²⁰ *Akbulut*, maddi ceza hukukunda aleyhe kıyasın yapılamayacağını, buna karşılık lehe kıyasın yapılabileceğini kabul etmektedir. Bu itibarla, yazara göre örneğin, “şahsi cezasızlık sebepleri veya cezayı kaldıran sebepler”le, “gönüllü vazgeçme”yle ilgili olarak ve “kusurluluğu kaldıran veya azaltan nedenlerde” kıyas yapılabilecektir (AKBULUT, Berrin: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 5. Bası, Ankara, Eylül 2018, sh. 113, 114). Ancak, kıyas yapılabilecek durumlara ilişkin herhangi bir örneklendirme yoluna gitmemekle, yazarın bu düşüncesi afakilikle maluldür.

³²¹ Objektif cezalandırılabilme şartlarına esas itibarıyla ilgili suç tanımında yer verilmektedir. Ancak **Yargıtay** bazı suç tanımlarıyla bağlantılı olarak **cezalandırılabilirliğin alanını daraltmak için, içtihat yoluyla da objektif cezalandırılabilme şartı ihdas edebilmektedir**. Yargıtay’a göre, TCK, m. 206’da tanımlanan “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçunun oluşabilmesi için, kişinin örneğin kimliğine ilişkin olarak yalan beyanına istinaden resmi belgenin düzenlenmiş olması gerekir: Yargıtay Ceza Genel Kurulu, **28.11.2019**, E. 2015/15-489, K. 2019/682.

ronik ortamdaki veriye belgede sahtecilik suçunun konusu olarak belge hüviyetini kazandırmamaktadır. **Elektronik ortamdaki veriye TCK, m. 204 ve devamı maddelerde tanımlanan suçların konusu olarak belge hüviyeti ancak bir kanuni düzenleme ile izafe edilebilir.**

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanmış olan ve hukuki sonuç doğurmaya elverişli içeriğe sahip bulunan elektronik veri, belge niteliğini haiz olacaktır. Ancak bu belge, TCK, m. 204 ve devamı maddelerde tanımlanan sahtecilik suçlarının konusunu oluşturmamaktadır. TCK’da tanımlanan sahtecilik suçlarının konusu olan belge, hukuki sonuç doğurmaya elverişli içeriğin kaydedilmiş olduğu kağıt veya metal levha gibi nesnel bir varlığa sahiptir. Oysa elektronik ortamda oluşturulmuş olan belgenin nesnel, fiziki bir varlığı bulunmamaktadır. Bu nedenle, TCK’nın belgede sahtecilik suçlarına ilişkin hükümlerini, elektronik ortamda oluşturulmuş olan belgelerle ilgili olarak uygulama imkanımız bulunmamaktadır. Aksi takdirde, kıyas yasağını ihlal etmiş oluruz.

Elektronik ortamda oluşturulmuş resmi veya özel belgelerle ilgili olarak, TCK’nın belgede sahtecilik suçlarına ilişkin hükümlerinin uygulanabilirliğini sağlamak için, bir kanuni düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Ancak, belirtelim ki, genişletici yorumla kıyas arasındaki sınırı belirlemek oldukça güçtür³²². Bu nedenle, belirsizliğin söz konusu olduğu somut durumlarda, kıyas yasağını ihlal etmemek ve dolayısıyla hukuk güvenliğini korumak uğruna, cezalandırılabilirliğin alanını dar tutmanın daha isabetli olacağı kanısındayız.

Bu nedenle, elektrik enerjisinin hırsızlık suçu açısından “taşınabilir mal” unsuru oluşturup oluşturmadığı tartışma konusu olmuştur.

Almanya İmparatorluk Yüksek Mahkemesi, elektrik enerjisinin taşınabilir bir mal olmadığına ve dolayısıyla, kaçak yoldan elektrik enerjisi tüketilmesi durumunda, kanunda tanımlanan hırsızlık suçunun oluşmayacağına karar vermiştir³²³. Çünkü, Yüksek Mahkemeye göre, aksinin kabulü halinde kıyas yasağı ihlâl edilmiş olacaktır. Bu nedenledir ki, Almanya’da kaçak yoldan elektrik enerjisinin tüketilmesi, bağımsız bir suç olarak düzenlenmiştir (Alman CK, § 248c)³²⁴.

Buna karşılık, Fransız Yüksek Mahkemesi, genişletici yorum yöntemini izlediğinden bahisle, kaçak yoldan elektrik enerjisi tüketiminin hırsızlık suçunu oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır³²⁵.

³²² Bkz. ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 100.

³²³ Bkz. JESCHECK(4) 121.

³²⁴ SCHÖNKE, Adolf/SCHRÖDER, Horst: *Strafgesetzbuch. Kommentar*, 23. Auflage, München, 1988, § 248c, kn. 1 vd.

³²⁵ Bkz. DÖNMEZER, Sulhi: *Kişilere ve Mala Karşı Cürümler*, 13. bası, İstanbul, 1990, no. 282, dn. 23.

Yargıtay, Fransız Yüksek Mahkemesinin görüşünü izleyerek, kaçak yoldan elektrik enerjisi tüketiminin hırsızlık suçunu oluşturacağını kabul etmişti^{326, 327}.

Yargıtay, genişletici yorumla kıyas arasındaki sınırın belirsizliğinden yararlanarak, “genişletici yorum” yaptığından bahisle, fakat aslında kıyas yöntemini işletmek suretiyle, kanunda açık bir şekilde suç olarak tanımlanmayan bazı fiillerin “suç” oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu yöntemle Yargıtay, başkasına ait telefon şebekesinin izinsiz ve yetkisiz olarak kullanılması halinde, hırsızlık suçunun olduğu yönünde içtihadta bulunmuştur. Bu içtihadın gerekçesinde Yargıtay, kıyas yapmadığını, sadece genişletici yorum yaptığını ifade etmiştir³²⁸.

Ancak, Yargıtay’ın İçtihadı Birleştirme Kararı olarak verdiği bu sonuç tatmin edici görülmediği için, 1991 yılında 3756 sayılı Kanunla, 765 s. –mülga– TCK’nın 491. maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir ikinci fıkra ilâve edilmişti. Buna göre; “*ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de taşınabilir mal sayılır*”. Bu hüküm sayesinde elektrik enerjisini taşınabilir mal olarak kabul etmek ve dolayısıyla, kaçak elektrik enerjisi tüketimini hırsızlık olarak nitelendirmek mümkün olmuştu.

Fakat, kanaatimizce, 491. maddeye ilâve edilen bu fıkraya rağmen, bedeli ödenmeksizin ve hukuk dışı yollarla başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden yararlanılması durumunda, hırsızlık suçu oluşmaz. Bu fiil, aslında *karşılıksız yararlanmanın* tipik bir örneğini oluşturmaktadır.

Nitekim, yeni TCK’nın “*Karşılıksız yararlanma*” başlıklı 163. maddesinin ikinci fıkrasında, “*Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, ... cezalandırılır.*” denilerek, başkasına ait telefon şebekesinin izinsiz ve yetkisiz olarak kullanılması durumunda karşılıksız yararlanma suçunun oluşacağı kabul edilmiştir. Bu maddenin **gerekçesinde** yer verilen şu ifadeler, yeterli açıklıktadır:

«... başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin ve hukuk dışı yollarla yararlanılması durumunda, hırsızlık suçu oluşmaz. Çünkü, ortada taşınabilir bir mal yoktur. Başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin ve hukuk dışı yollarla yararlanılması fiili, karşılıksız yararlanmanın tipik bir örneğini oluşturmaktadır.

³²⁶ Kaçak yoldan elektrik enerjisi tüketmenin hırsızlık suçunun basit (temel) şeklini oluşturduğu hakkında bkz. 6.CD, 18.5.1987, 3948/5337 (YKD, Mart 1988, sh. 430). Ayrıca bkz. CGK, 25.10.1976, 6-433/444 (Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, no.282, dn. 23bis); 2.CD, 10.1.1951, 30/49; 2.CD, 9.12.1948, 11693/12159. (Önder, Genel Hükümler I, sh.126).

³²⁷ Aynı doğrultuda görüş için bkz. İÇEL/DONAY(3), sh. 84, 125.

³²⁸ Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 6.4.1990 tarihli ve E. 1989/2, K. 1990/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı (RG: 29 Haziran 1990/20563).

Kamu veya özel kuruluşlarca kurulmuş bulunan telli ve telsiz telefon hatları ile sistemlerinden veya elektromanyetik dalgalar yolu ile şifreli veya şifresiz yayın yapan televizyon yayınlarından sahiplerinin veya zilyetlerinin rızası olmadan yararlanılması durumunda da bu suç oluşur. Bu durumlarda bir mal söz konusu olmadığı için hırsızlık suçunun oluştuğundan söz edilemez.»

V. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi

Kanunilik ilkesi bakımından 5326 sayılı *Kabahatler Kanununun* 4. maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir:

“(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükümün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.

(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.”

Bu maddenin gerekçesi şu şekildedir:

“Madde metninde, suçta kanunilik ilkesine nazaran, kabahatler açısından daha esnek bir sistem kabul edilmiştir. Buna karşılık, ikinci fıkrada, idari yaptırımlar açısından, cezada kanunilik ilkesine paralel bir hükme yer verilmiştir.”³²⁹

Dikkat edilmelidir ki, bu düzenleme ile, “beyaz hüküm” uygulaması olarak yukarıda açıklamış bulunduğumuz yöntemin kabahatlerle ilgili olarak uygulanabilmesinin kanuni temeli oluşturulmuş olmaktadır.

VI. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması

A. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Zaman Bakımından Uygulama İlkeleri

Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin yanı sıra; ceza hukukunun kişi hak ve hürriyetleri açısından güvence oluşturması amacıyla kabul edilen diğer bir **kurala** göre; fiili işlediği zaman yürürlükte olan kanunlara göre suç teşkil ediyorsa kişi cezalandırılabilir. Bir fiil işlendikten sonra yürürlüğe giren kanunda suç olarak tanımlanmışsa; bu kanun geçmişe yürütülerek fail cezalandırılmaz³³⁰.

³²⁹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840.

³³⁰ Anayasa Mahkemesi, 11.4.2019, E.2019/9, K.2019/27:

“13. Anayasa’nın 38. maddesinin birinci fıkrasında “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” denilerek suçun kanuniliği; üçüncü fıkrasında da “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” denilerek cezanın kanuniliği ilkesi güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın anılan maddesinde yer alan suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca hangi fiillerin yasaklandığının ve bu yasak fiillere verilecek cezaların hiçbir kuşkuyla yer bırakmayacak biçimde kanunda

gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Kişilerin yasak fiilleri önceden bilmeleri düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

14. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin somutlaştırıldığı uluslararası sözleşmelerde de yer almaktadır. Bu ilke Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (Sözleşme) "*Kanunsuz ceza olmaz*" kenar başlıklı 7. maddesinin birinci paragrafında "*Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Aynı biçimde, suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.*" şeklinde; Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 15. maddesinin birinci paragrafında ise "*Hiç kimse, işlendiği zamanda ulusal ya da uluslararası hukuk bakımından suç sayılmayan bir fiil ya da ihmâl yüzünden suçlu sayılamaz. Suç sayılan bir fiile, işlendiği zaman yürürlükte olan bir cezadan daha ağır ceza verilemez. Fiilin işlenmesinden sonra yasalarda bu fiile karşılık daha hafif bir ceza öngörülecek olursa, fiili işleyene bu ikinci ceza uygulanır.*" biçiminde düzenlenmiştir.

15. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi Anayasa'nın 13. maddesinde ifade edilen temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceğine ilişkin kuralın suç ve cezalar yönünden özel düzenlemesi olarak değerlendirilebilir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, cezalandırmanın temel haklara etkisinden kaynaklanan özel önemi nedeniyle zaman içinde bir ceza hukuku kavramı olarak alt ilkeler de içerecek şekilde gelişmiştir.

16. Bu bağlamda toplumun ihtiyaçlarına göre suç sayılan fiiller için uygulanacak cezalar, nitelik ve nicelik olarak zamanla değişebilmektedir. Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren kanunla bir suç için daha hafif bir ceza öngörülebileceği gibi daha ağır bir ceza da belirlenebilir. Hukuki belirliliğin ve hukuk güvenliğinin gereği olarak Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "*...kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez*" hükmüyle aleyhe kanunun geçmişe uygulanması yasaklanmıştır. Ceza normlarının zaman bakımından uygulanmasını düzenleyici nitelikteki bu kural kanunilik ilkesinin bir alt ilkesi olan *aleyhe kanunun geçmişe uygulanması yasağı* olarak ifade edilmektedir. Bu yasak kişi özgürlüğü lehine kabul edilmiş bir güvence niteliğindedir.

17. Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren kanunun aynı fiili suç olmaktan çıkarması veya aynı suç için daha hafif bir ceza öngördüğü durumlarda ise diğer bir alt ilke olan *lehe kanunun uygulanması ilkesi* gündeme gelmektedir. Sonraki kanunun fiili suç olmaktan çıkarması veya daha hafif bir ceza öngörmesi durumunda lehe kanundan söz edilir. Aleyhe kanunun geçmişe uygulanması yasağından farklı olarak lehe kanunun uygulanması ilkesine ilişkin bir hükme Anayasa'nın 38. maddesinde açıkça yer verilmemiştir. Bununla birlikte aynı maddede suç için mutlaka fiilin işlendiği zaman yürürlükte olan kanunun öngördüğü cezanın verilmesi yönünde bir kural da bulunmamaktadır.

18. Fiilin işlenmesinden, hükmün kesinleşmesine kadar geçen ceza muhakemesi sürecinde bir suç için fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan ve daha sonra yürürlüğe giren kanun olmak üzere uygulanması mümkün birden fazla kanun hükmü söz konusu olabilmektedir. Suç nedeniyle başta hürriyeti bağlayıcı cezalar olmak üzere uygulanan çeşitli ceza ve güvenlik tedbirleri temel hak ve özgürlüklere müdahale oluşturduğundan, Anayasa cezayı ağırlaştıran kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş suçlara uygulanmasını açık biçimde yasaklamıştır. Hukuki belirliliğin ve hukuk güvenliğinin bir sonucu olan bu yasak, aynı zamanda suçun işlendiği tarihteki kanuna göre lehe olan sonraki kanunun uygulanmasını da gerekli kılmaktadır. Zira işlendiği tarihte suç sayılan bir fiilin daha sonra yürürlüğe giren kanun ile suç olmaktan çıkarılması veya ilga edilen kanuna nazaran anılan suç fiiline daha hafif bir ceza öngörülmesi durumunda mülga kanunun aleyhe hükümlerinin uygulanmaya devam edileceğinin kabul edilmesi, suçların ve cezaların ancak kanunla belirleneceğini emreden suç ve cezaların kanuniliği ilkesi karşısında bireylerin objektif olarak beklemeyecekleri dolayısıyla öngöremeyecekleri bir ceza ile cezalandırılmaları sonucunu doğuracaktır. Bunun ceza hukuku alanında kişilerin hukuki güvenliklerini anayasal güvenceye bağlamayı amaç edinen suç ve cezaların kanuniliği ilkesiyle bağdaştırılması mümkün değildir.

19. Öte yandan lehe ceza kanununun geçmişe uygulanması hukuk devletiyle bağlantılı olarak adalet ve hakkaniyet ilkelerinin de bir gereğidir. Gelişen sosyal düzen ve değişen toplumsal ihtiyaçlar karşısında artık suç oluşturmadığı kabul edilen veya daha hafif ceza öngörülen bir fiilin yalnızca daha önce işlenmiş olması nedeniyle daha ağır bir yaptırıma tabi tutulması adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

20. Anılan hususlar birlikte değerlendirildiğinde ceza yargılamasında lehe kanunun uygulanmasının Anayasa'nın 38. maddesinde düzenlenen suçta ve cezada kanunilik ilkesi kapsamında anayasal bir zorunluluk olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

21. Diğer yandan uluslararası hukukta lehe kanun uygulamasının suçta ve cezada kanunilik ilkesinin bir unsuru olarak görüldüğü konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'de de fiilin işlenmesinden sonra kanunlarda bu fiile karşılık daha hafif bir ceza öngörülmesi durumunda fiili işleyene bu ikinci cezanın uygulanacağı ifade edilerek anılan ilke açıkça düzenlenmiştir.

22. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasıyla benzer içerikte olan Sözleşme'nin 7. maddesinin birinci paragrafına ilişkin içtihadında lehe kanunun uygulanması ilkesinin Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı dâhil bütün temel insan hakları metinlerinde tanındığını, artık Avrupa ve uluslararası ceza hukukunun temel bir ilkesi olduğunu, yargılama yapan mahkemenin suç oluşturan eyleme kanun koyucunun orantılı olarak belirlediği cezayı vermesinin 7. maddenin temel bir unsuru olan hukukun üstünlüğü ilkesiyle uyumlu olduğunu ifade etmektedir. Mahkeme ayrıca suç işleyene sadece suç işlediği tarihte öngörüldüğü gerekçesi ile daha ağır bir ceza verilmesinin ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı bulunduğunu, bunun aynı zamanda suçun işlendiği tarihten sonra meydana gelen bütün yasal değişiklikleri ve toplumun o suç karşısındaki yaklaşım değişikliğini görmemek anlamına geldiğini, lehe olan ceza hükmünün geriye yürütmesi ilkesinin cezaların öngörülebilir olması gerekliliğinin bir uzantısı olduğunu, buna göre suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan ceza kuralı ile kesin bir hükmün verilmesinden önce kabul edilen bir ceza kuralı farklı ise hâkimin sanığın lehine olan ceza kuralını uygulaması gerektiğini belirtmiştir (*Scoppola/İtalya*(no. 2) [BD], B. No: 10249/03, 17/9/2009, §§ 105-109).

23. Nitekim sözü edilen anayasal ilke doğrultusunda düzenlenen 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "*Zaman bakımından uygulama*" başlıklı 7. maddesinin (2) numaralı fıkrasında lehe kanunun uygulanması ilkesi "*Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur*" şeklinde ifade edilmiştir.

24. İtiraz konusu kuralın yer aldığı Kanun 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 17. maddede ile 1447 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kuralın yer aldığı geçici madde ile Kanun'un geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

25. Mülga Kanun'un 12. maddesinde belirtilen fiiller için bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezası öngörülmüş iken 6750 sayılı Kanun'un 16. maddesinde yer alan suçları işleyenlere, güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezasının uygulanması düzenlenmiştir.

26. Kural, hukuk ve ceza normu ayrımı yapmaksızın Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görülmekte olan davalara Kanun hükümlerinin uygulanmamasını öngörmektedir. Bu durum ceza hükümlerinin uygulanması bakımından farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede kural 6750 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden önce işlenen ve ceza davası açılmış bir suç yönünden bu Kanun'un ceza hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle kural, mülga Kanun döneminde işlenmiş ve anılan Kanun yürürlükte iken ceza davası açılmış suçlar hakkında önceki ve sonraki kanun hükümlerinden lehe olanın tespitine ve sonraki Kanun hükümlerinin lehe olması durumunda bunların uygulanmasına imkân vermemektedir. Bu durum suçta ve cezada kanunilik ilkesi kapsamında olan lehe kanunun uygulanması ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

27. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir."

Yeni suçlar ihdas eden bir kanun, ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen fiiller bakımından uygulama kabiliyeti bulur (**Geriye yürüme yasağı**)^{331,332}.

Keza, bir suçun unsurlarında, suçun karşılığında öngörülen yaptırımlarda, bu suçtan dolayı mahkûmiyetin kanuni neticelerinde sonradan yürürlüğe giren bir

³³¹ Rücu yasağı, makale ademi şümül, Regressverbot.

³³² Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **1.11.2011** tarihli ve E. 2011/7-31, K. 2011/219 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, sanıklar 1988 yılında Ankara'da iki farklı şirket kurarlar. Bu şirketler bünyesinde görülür bir ticari faaliyette bulunulmaz. Ancak, bu arada sanıklar ile yakınlarının banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarlarda para transferleri olur.

Bu yüklü para transferlerinin dikkat çekmesi üzerine, sanıklar hakkında "karapara" aklama suçunu işledikleri şüphesiyle soruşturma yapılır ve kamu davası açılır.

Bu dava sürecinde, sanıklar hesaplarına aktarılan yüklü miktardaki yabancı paraların Hindistan'daki NFL şirketi ile aralarında imzalamış oldukları üre satış sözleşmesi gereğince bu şirketten tahsil ettikleri savunmasında bulunurlar.

Sanıklar, dolandırıcılık suçunu işlemediklerini, kaldı ki, işlemiş olsalar bile, bu suçu "karapara aklama" suçunun ilk defa tanımlandığı 4208 s. Kanunun yürürlüğe girdiği 19.11.1996 tarihinden önce işlenmiş olduğunu ve dolayısıyla, bu suçtan elde edilen para ile ilgili olarak "karapara aklama" suçuna ilişkin hükümlerin uygulanamayacağını ileri sürerler.

Ancak, "karapara" aklama suçunu işledikleri iddiasıyla açılan davada Mahkeme, bu olayda sanıkların Hindistan'daki NFL şirketi ile imzaladıkları üre satış sözleşmesi bağlamında bu şirket yetkililerini dolandırdığını ve bu Şirket tarafından kendilerine ve yakınlarına ait banka hesaplarına aktarılan paraların dolandırıcılık suçundan elde edilmiş paralar olduğunu, bu paraları meşru bir yolla elde etmiş izlenimi uyandırmak için çeşitli işlemlere tabi tuttuklarını kabul ederek, haklarında 5237 s. TCK hükümlerine istinaden mahkûmiyet hükmü tesis etmiştir. (Ankara 7. Asliye Ceza Mhk, 7.7.2008, 1303/482).

Bu olayda sanıklar hakkında Türkiye'de dolandırıcılık suçundan dolayı açılmış bir dava bulunmamakla birlikte, Hindistan'da bir devlet iştiraki olan NFL Şirketinin açtığı ihale kapsamında suç işlediklerinden bahisle Hindistan'da açılmış bir dava bulunmaktadır. Ancak, "karapara" aklama suçunun görüldüğü Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi, bekletici mesele olarak bu davanın sonucunu beklememiştir.

"Karapara" aklama suçunun işlendiği iddiasıyla açılan davada Mahkeme, sanıkların dolandırıcılık suçunu işlediklerini kabul etmekle birlikte, sanıklar hakkında bu suçtan dolayı mahkûmiyet hükmü tesis etmemiştir.

Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 7. Ceza Dairesi, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin veya namı diğerle "karapara"nın aklanması suçunun oluşabilmesi için, öncül suçun da "karapara"yı aklama fiilini suç olarak tanımlayan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenmesi gerektiği yönünde içtihadta bulunmuştur (29.12.2010, 15629/17189). Buna göre, hukuk sistemimizde "karapara" aklama suçunun ilk defa tanımlandığı 4208 s. Kanunun yürürlüğe girdiği **19.11.1996 tarihinden önce** işlenmiş olan dolandırıcılık suçundan elde edilmiş olan paranın meşru bir yolla elde edilmiş olduğu izlenimi uyandıracak şekilde işlemlere tabi tutulması fiilleri **bu tarihten sonra** işlenmiş olsa bile, "karapara" aklama suçu oluşmayacaktır.

Bu Karara Yargıtay C. Başsavcılığınca itiraz edilmiştir. İtiraz üzerine, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulunda görüşülmüş ve Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararındaki gerekçe benimsenerek, itiraz reddedilmiştir (CGK, **1.11.2011**, E. 2011/7-31, K. 2011/219).

Bu içtihad katılmak mümkün değildir. Lehe kanunun belirlenmesinde **suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu oluşturan fiilin işlendiği tarihi** esas almak gerekir. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun oluşabilmesi için, **suçun konusunu oluşturan para ve sair malvarlığı değerinin elde edildiği suçun işlendiği tarihin bir önemi bulunmamaktadır.**

kanunla failin **aleyhine** olacak şekilde değişiklikler yapılması durumunda; bu kanun, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller bakımından uygulanamayacaktır.

Ancak, bu kuralın **istisnası** mevcuttur. Buna göre, bir fiil, bilahare yürürlüğe giren yeni bir kanun ile suç olmaktan çıkarılmış ise, işlendiği zaman yürürlükte olan kanuna göre suç oluşturmaya rağmen; faili cezalandırılmayacaktır. Yani, bu durumda sonradan yürürlüğe giren kanun, failin **lehine** sonuç doğurduğu için, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller bakımından da, geçmişe yönelik olarak, uygulama kabiliyetine sahip olacaktır. Yine sonradan yürürlüğe giren kanun, bir suçun unsurlarında, yaptırımlarında, bu suçtan dolayı mahkûmiyetin kanuni neticelerinde failin **lehine** olacak şekilde değişiklikler yapması durumunda, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller bakımından da uygulanabilecektir³³³.

Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin bu ilkeler, yeni TCK'nın “Zaman bakımından uygulama” başlıklı 7. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:

“(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılmaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

(3) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.”

Maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 765 s. Kanunun 2. maddesinden iktibas edilmiştir; üçüncü ve dördüncü fıkraları ise, yeni hükümlerdir.

Zaman bakımından uygulamaya ilişkin ilkeler, sonradan yürürlüğe giren kanunla bir **suçun unsurlarında**, sair **cezalandırılabilme şartlarında**, suçun karşılığında öngörülen **ceza hukuku yaptırımlarında** ve bir **cezaya mahkûm olma-**

³³³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, KHUKA, Haziran-Ekim 2000, sh. 90 vd.; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku (3), sh. 51; KATOĞLU, Tuğrul: *Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması*, Ankara, 2008.

ya bağlı kanuni neticelerde bir değişiklik yapılması durumunda, dikkate alınacaktır.^{334,335}

Yeni TCK'da zaman bakımından uygulama kuralı belirlenirken; bunun, sadece cezalarla ilgili olarak değil, güvenlik tedbirleri bakımından da, yani ceza hukuku yaptırımlarının bütünü için geçerli olduğu vurgulanmıştır.³³⁶

B. Lehe Kanunun Belirlenmesinde İzlenmesi Gereken Yöntem

Somut olaya ilişkin olarak lehe kanunun belirlenmesinde sadece belirli bir hüküm göz önünde bulundurulamaz. Bir kanun hükümlerinin olaya bir bütün olarak uygulanması sonucuna bakılmak suretiyle lehe kanunun belirlenmesi yoluna gidilmelidir. Bu düşünceyle, yeni **TCK'nın Yürürlük ve Uygulama**

³³⁴ Tazyik hapsi, her ne kadar bir yükümlülüğün yerine getirilmesi bağlamında başvuru bir zorlama aracı ise de, kanunda bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi suç olarak tanımlanmış iken, bilahare yapılan bir kanuni değişiklikle bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin suç olmaktan çıkarılması ve fakat yerine getirilmesini sağlamak için tazyik hapsi uygulanmasına imkan tanınması halinde, yine maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulama kurallarını gözönünde bulundurarak uygulama yapmak gerekir.

Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**, bir kararında bu ilkeye sadık kalmış ise de, doğru olmayan bir sonuca varmıştır. Ceza Genel Kurulunun Kararında, bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinin suç olmaktan çıkarılmasına karşılık bunun yerine getirilmesini sağlamak için tazyik hapsine başvurulmasını öngören kanuni düzenlemenin, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesini suç olarak tanımlayan kanuni düzenlemeye nazaran daha aleyhe olduğu sonucuna varılmıştır:

“Nafaka borcunu ödememe eylemi 2004 sayılı İcra ve İflas Yasasının 344. maddesinde on günden üç aya kadar hafif hapis cezası ile yaptırım altına alınmış iken, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Yasanın 5349 sayılı Yasanın 3. maddesi ile değişik 7. maddesinin 1. fıkrası ile “Kanunlarda hafif hapis veya hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımlar idari para cezasına dönüştürülmüştür...”, hükmü uyarınca idari para cezasına dönüşmüştür. Diğer yandan 1 Haziran 2005 gün ve 25832 mükerrer sayılı R.G’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 31.05.2005 gün ve 5358 sayılı Yasanın 15. maddesi ile eylemin yaptırımı üç aya kadar **tazyik hapsi** olarak belirlenmiş ise de, aleyhe olan bu değişikliğin 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar açısından uygulanma olanağı bulunmamaktadır.”; CGK, **14.10.2008**, E. 2008/16.HD-199, K. 2008/217.

³³⁵ Bir düzenlemenin, usul hukukuna ilişkin olmasına rağmen, maddi ceza hukukuna ilişkin hükümler içermesi durumunda da maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulama kurallarını dikkate almak gerekmektedir: Anayasa Mahkemesi, 25.6.2020, E. 2020/16, K. 2020/33 (RG: 19 Ağustos 2020/31218); Anayasa Mahkemesi, 14.1.2021, E. 2020/81, K. 2021/4 (RG: 16 Mart 2021/31425); Anayasa Mahkemesi, 21.4.2022, E. 2020/87, K. 2022/44 (RG: 2 Ağustos 2022/31911).

³³⁶ Böylece, Türk doktrinindeki bir tartışma sona erdirilmiş olmaktadır.

Doktrinde bir görüşe göre; güvenlik tedbirleri bakımından *derhal uygulama* kuralı geçerlidir. Yani, fail hakkında işlediği suçtan dolayı bir güvenlik tedbirine hükmedilmesinin söz konusu olduğu bir durumda, fiil ne zaman işlenmiş olursa olsun, *hüküm zamanında yürürlükte olan kanun* dikkate alınacak ve bu kanuna göre uygulama yapılacaktır (DÖNMEZER/ERMAN I, no. 344; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 140). Buna karşılık, diğer bir görüşe göre ise; zaman bakımından uygulamaya ilişkin söz konusu ilkeler, hürriyeti kısıtlayıcı güvenlik tedbirleri bakımından da dikkate alınmalıdır (İÇEL/DONAY(3), sh. 91-93).

Şekli Hakkında 5252 sayılı Kanuna özel bir hüküm konulmuştur. Buna göre;

“Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir.” (m. 9, f. 3).

Yeni TCK’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporunda; bu hükmün **gerekçesi** bağlamında şu açıklamalara yer verilmiştir³³⁷:

“Ceza hukukunun kişi hak ve hürriyetleri açısından güvence oluşturması amacıyla kabul edilen zaman bakımından uygulama kurallarına göre; fiili işlediği zaman yürürlükte olan kanunlara göre suç teşkil ediyorsa fail cezalandırılabilir. Bir fiil işlendikten sonra yürürlüğe giren kanunda suç olarak tanımlanmışsa; bu kanun geçmişe yürütülerek fail cezalandırılmaz. Yeni suçlar ihdas eden bir kanun, ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen fiiller açısından uygulama kabiliyeti bulur.

Keza, bir suçun unsurlarında, cezasında, bu suçtan dolayı mahkûmiyetin kanuni neticelerinde sonradan yürürlüğe giren bir kanunla failin aleyhine değişiklikler yapılması durumunda; bu kanun, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller açısından uygulanamayacaktır.

Ancak, bu kuralın istisnası mevcuttur. Buna göre, bir fiil, bilahare yürürlüğe giren yeni bir kanun ile suç olmaktan çıkarılmış ise, işlendiği zaman yürürlükte olan kanuna göre suç oluşturmaya rağmen; fail cezalandırılmayacaktır. Yani, bu durumda sonradan yürürlüğe giren kanun, failin lehine sonuç doğurduğu için, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller açısından da (geçmişe yönelik olarak) uygulama kabiliyetine sahip olacaktır. Yine sonradan yürürlüğe giren kanun, bir suçun unsurlarında, cezasında, bu suçtan dolayı mahkûmiyetin kanuni neticelerinde failin lehine değişiklikler yapılması durumunda, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller açısından da uygulanabilecektir.

Zaman bakımından uygulamaya ilişkin bu ilkeler, sonradan yürürlüğe giren kanunla bir suçun unsurlarında, sair cezalandırılabilme şartlarında, cezasında ve hatta, güvenlik tedbirlerinde değişiklik yapılması durumunda, dikkate alınacaktır.

Değiştiren kanunla değişikliğe uğrayan kanunlardan hangisinin lehe hükümler içerdiği, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin somut olaya uygulanmasıyla ortaya çıkacak olan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenecektir.”

³³⁷ TBMM Adalet Komisyonunun, yeni TCK’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin 3.11.2004 tarihli ve Esas 1/592, Karar 64 sayılı Raporu, in: TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 675.

Yargıtay, verdiği kararlarda yeni TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 5252 sayılı Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasındaki prensibe sadık kalmıştır:

“hüküm fıkrasında 5237 s. TCK'nın olayla ilgili bütün hükümlerinin yargı denetimine olanak verecek biçimde uygulanması, ortaya çıkan sonucun kesinleşmiş olan hükmün sonucu ile karşılaştırılması (ve bu suretle), lehe olan hükmün belirlenmesi; 5237 s. Yasa ile kurulan hüküm lehe ise, uygulamanın ona göre yapılması; aksi halde, 5237 s. Yasa ile hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekir.”³³⁸

Yeni TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 5252 sayılı Kanuna konan bu hükme göre; önceki ve sonraki kanunların bütün hükümleriyle somut olaya uygulanmasının sonuçlarının birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe kanun belirlenecektir.

Lehe kanunun belirlenmesinde, bir kanunun **hüküm tesis edilinceye kadarki hükümleri** kendi içinde bir bütün olarak somut olaya uygulanmak gerekir. Buna karşılık, hüküm verildikten sonraki **infaz aşamasında uygulanabilecek olan kanun hükümlerini** ise, lehe kanunun belirlenmesinde ayrıca değerlendirmek gerekecektir. Böylece, **çapraz uygulama** yapılabilecektir³³⁹. Örneğin hüküm tesisine kadarki kanuni düzenlemeler itibarıyla, yeni TCK; buna karşılık, hükümlenen cezanın infazı bakımından ise –mülga– 647 s. İnfaz Kanunu, lehe hükümler içerdği için uygulanabilecektir.

³³⁸ 1.CD, 30.12.2005, 5076/5009..

³³⁹ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu'nun 11.10.2011** tarihli ve E. 2011/1-179, K. 2011/211 sayılı Kararı, **çapraz uygulama** bakımından önem taşımaktadır.

Silifke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, TK hakkında, 25.5.2004 tarihinde işlediği kasten öldürme suçuna teşebbüsten dolayı, lehe hükümler içermesi itibarıyla 5237 s. TCK hükümlerine göre 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilir.

Adli sicil kaydında TK'nın, Mut Asliye Ceza Mahkemesince 25.04.2000 gün ve 221-90 sayılı ile 765 sayılı Yasanın 266/1, 59 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri uyarınca verilmiş 1.516.666 Lira ağır para cezasına ilişkin, 27.06.2000 tarihinde kesinleşip, 16.04.2004 tarihinde infaz edilmiş geçmiş hükümlülüğü bulunmaktadır.

Esas mahkemesince, hüküm kurulurken, sanığın sabıkasında yer alan hükümlülük tekröre esas alınarak cezasının 5237 s. TCK'nın 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektilmesine karar verilir.

Bu olaya ilişkin Ceza Genel Kurulu'nun kararına göre, “5237 s. TCK'nın 58. maddesi uyarınca kişinin mükerrir sayılması için ilk hükmün kesinleşmesinden sonra ikinci suçun 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenmesi yeterli olup, ilk suçun 1 Haziran 2005 tarihinden önce veya sonra işlenmesinin herhangi bir önemi yoktur. İkinci suçun 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlendiği durumlarda ise 58. maddenin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle; 25.5.2004 tarihinde işlenen kasten öldürme suçuna teşebbüsten hüküm kurulurken 5237 s. TCK hükümleri lehe kabul edilerek yapılan uygulamada, suç tarihinde yürürlükte bulunmayan, **aleyhe olan ve infazı ilgilendiren 58. maddenin uygulama olanağı bulunmadığından yerel mahkeme hükmünün bozulması gerekmektedir.”** Ayrıca bkz. CGK, **22.11.2011**, 2011/4-203, K.2011/238; CGK, **22.11.2011**, E. 2011/9-204, K. 2011/239.

Yeni TCK'nın sistematigi ve düzenlemelerindeki felsefi düşünce farklılığı dolayısıyla, lehe kanun belirlenmesi ile ilgili olarak belli bir kuruma ilişkin düzenlemelerin yalnız başına ele alınıp 765 sayılı Kanundaki düzenlemelerle karşılaştırılması halinde sağlıklı bir sonuca varılması mümkün gözükmemektedir.

Bu nedenle, yeni TCK'ya ilişkin 5252 sayılı Yürürlük Kanununun 9. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği gibi, bir olaya eski kanunlarla yeni kanunlar bir bütün olarak uygulanacaktır. Bu uygulama sonucunda ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe kanun belirlenecektir.

Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, lehe kanunun belirlenmesinde **hükmün kurulması aşamasında uygulanması gereken düzenlemelerle hükmün infazına ilişkin düzenlemeleri** birlikte değil, ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

Dikkat edilmelidir ki, hükmün kurulması aşamasında uygulanması gereken düzenlemelerin münhasıran bir kanun kapsamında olması gerekmemektedir. Şöyle ki, cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler 765 s. TCK ile 647 s. İnfaz Kanununda düzenlenmiş bulunmaktaydı. Keza, 765 s. TCK'dan farklı olarak tekerrür müessesesi, 5237 s. TCK ile 5275 s. İnfaz Kanununda birlikte düzenlenmektedir. Aynı şekilde koşullu salıverilme müessesesi ile ilgili olarak, mülga 765 s. TCK ile 647 s. İnfaz Kanununun her ikisinde de hükümler bulunmaktaydı. Buna karşılık, bir infaz müessesesi olan ve hükmün kurulması aşamasında uygulanabilecek bir mahiyet taşımayan koşullu salıverilme, sadece yeni (5275 s.) İnfaz Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle, lehe kanunun belirlenmesi bağlamında yapılan değerlendirmede sadece bir kanunu değil, bir müesseseyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanunları birlikte göz önünde bulundurmak gerekmektedir³⁴⁰.

Yargıtay içtihatları da yeni ceza hukuku mevzuatının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aynı yönde gelişmiştir³⁴¹.

³⁴⁰ Kitabımızın ilk dört basısında, özellikle geçiş dönemi itibarıyla büyük önem taşıdığı için, çeşitli örnek olaylardan hareketle lehe kanun uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir (Bkz. 4. bası, sh. 126 vd.).

³⁴¹ “765 sayılı TCY’nın 2, 5237 sayılı TCY’nın 7 ve 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesinin; “*Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir.*” hükmü, 23.02.1938 gün ve 23/9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve öğretideki görüşler birlikte değerlendirildiğinde, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.04.2007 gün ve 1-32/97 sayılı kararlarında da vurgulandığı üzere, lehe yasa belirlenmesi yöntemi; sabit kabul edilen olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümlerinin birbirine karıştırılmaksızın uygulanmak suretiyle ayrı ayrı sonuçlar belirlenmesini ve bunların karşılaştırılmasını gerektirmektedir. Lehe yasanın saptanması için, maddi olaya suç tarihinde yürürlükte bulunan yasalar ile sonradan yürürlüğe giren yasaların hiçbir hükmü karıştırılmadan bir bütün halinde uygulanmasını ve uygulama sonucunda ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. **Ancak bu karşılaştırmada, hükmün tesisi aşamasında uygulanması gereken normlarla, hükmün infazına ilişkin normlar birlikte değil, ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.** Bu değerlendirmede hükmün

C. Ceza İnfaz Rejiminde Değişiklik Yapan Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması

Ceza infaz rejimine ilişkin kanuni düzenlemeler, kural olarak, **derhal** uygulanır (**Derhal uygulama kuralı**). Bu Kural, yeni TCK'nın 7. maddesinin üçüncü fıkrasında açıkça ifade edilmiştir.

Ancak, söz konusu fıkra göre; çeşitli infaz müesseselerine ilişkin hükümler bakımından, derhal uygulama kuralının değil, maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulama kurallarının uygulanması gerekmektedir:

“Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.” (m. 7, f. 3)

Bu hükmün **gerekçesi**, ayrıca izaha gerek bırakmayacak açıklıktadır:

“Yeni Türk Ceza Kanununun benimsediği yaptırım sisteminde amaç hükümlüyü ıslah ederek yeniden topluma kazandırmak, hükümlünün toplum açısından oluşturduğu tehlikeyi azaltmak olduğuna göre, aralarında bir ayırım yapmaksızın, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı bakımından derhal uygulama kuralı benimsenmiştir. Bu kuralı açık bir şekilde ifade edebilmek için, Kanunun 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılması gereği hasıl olmuştur. Ancak, bu düzenlemede hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrüre ilişkin hükümler bakımından, bu kuraldan ayrılmıştır. Kanunun sisteminde bir ceza infaz rejimi olarak kabul edilen hapis cezasının ertelenmesi ile koşullu salıverilme ve mükerrirlere özgü infaz rejimi bakımından, birinci ve ikinci fıkralardaki zaman bakımından uygulama kuralları uygulanacaktır.”³⁴²

Aslında bu hükümle, koşullu salıverilme gibi, hapis cezasının ertelenmesine ve tekerrüre ilişkin düzenlemeler, **ceza infaz rejimine ilişkin hükümler** olarak kabul edilmekle birlikte, maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulama kurallarına tabi kılınmışlardır³⁴³.

tesisi aşamasında uygulanması gereken düzenlemelerin aynı yasa kapsamında bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, sadece bir yasa değil bir müesseseyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasalar birlikte değerlendirilecektir.”: CGK, 17.07.2007, 2007/1-168, 2007/173; CGK, 17.07.2007, 2007/1-157, 2007/168. Ayrıca bkz: CGK, 19.06.2007, 2007/1-122, 2007/153; CGK, 19.06.2007, 2006/9-64, 2007/147; CGK, 29.05.2007, 2007/6-111, 2007/121; CGK, 29.05.2007, 2007/6-110, 2007/120; CGK, 17.04.2007, 2007/1-32, 2007/97; CGK, 11.07.2006, 2006/2-190, 2006/186; CGK, 10.10.2006, 2006/3-207, 2006/207.

³⁴² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 1/2.

³⁴³ Yargıtay, 1973 yılında verdiği bir kararda koşullu salıverilmenin “maddi hukuka ilişkin” bir müessese olduğunu ve değişiklikten önceki lehe hükmün mahkûm açısından bir “müktesep hak” oluşturduğunu kabul etmişti: 6. CD., 5.7.1973, 6567/6535 (YKD, Ekim 1976, sh. 1518 vd.).

Yüksek Mahkemenin bu görüşlerine iştirak etmiyoruz. Çünkü, şartla salıverilme, hapis cezasının infaz suretinden başka bir nitelik taşımamaktadır. Ayrıca, **infaz rejimine ilişkin kanuni düzenlemeler, kişiler açısından bir kazanılmış (müktesep) hak oluşturmaz.**

Örnek olarak cezanın ertelenmesi bakımından lehe kanunun belirlenmesine ilişkin bir değerlendirme yapmak gerekirse, şu hususlara dikkat etmek gerekir:

Yeni TCK'da bir ceza infaz rejimi olarak düzenlenmiş olan erteleme açısından zaman bakımından uygulama kuralları uygulandığında şu sonuçlar ortaya çıkacaktır:

Yürürlükten kaldırılan 647 s. İnfaz Kanununun 6. maddesine göre; mahkûm olunan ceza "*bir yıla kadar (bir yıl dahil) ağır hapis ve iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis ... cezası*" ise, ertelenebilir.

Buna karşılık, yeni TCK'da salt hapis cezası kabul edilerek, "ağır hapis" ve hapis cezası ayırımı kaldırılmıştır. Keza, yeni TCK'ya göre, "*iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir.*" (m. 51, f. 1).

İki yıl veya daha az süreyle "ağır hapis" cezasına mahkûmiyet halinde, ceza bir yıldan fazla olduğu takdirde, 647 s. (mülga) Kanunun 6. maddesi hükmü karşısında ertelemeden yararlanma imkanı bulunmamaktaydı. Halbuki, yeni TCK'daki düzenlemeye göre, belirtilen durumda ertelemeden yararlanılabilecektir. Görülmektedir ki; yeni TCK'nın ertelemeye ilişkin bu hükmü, 647 s. (mülga) Kanunun düzenlemesine nazaran lehe hükümdür. Bu durum karşısında, yeni TCK'nın yürürlük tarihinden önce işlenmiş olan bir suç nedeniyle mahkûm olunan "ağır hapis" cezasının³⁴⁴ miktarının iki yıl veya daha az olması halinde, yeni TCK'nın lehe olan hükmü uygulanarak erteleme yönünde karar verilebilecektir.

Keza, 647 s. (mülga) İnfaz Kanununun 6. maddesine göre; mahkûm olunan cezanın ertelenebilmesi için, daha önce "*para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olma*"mak gerekir. Bu düzenlemeye göre, daha önce mahkûm olunmuş olan hapis cezası, süresi ne olursa olsun, ertelemeye engel teşkil etmekteydi. Buna karşılık, yeni TCK'ya göre, ertelemeden yararlanabilmek için, "*daha önce ... üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş*" olmak gerekir. Görülmektedir ki; yeni TCK'nın ertelemeye ilişkin bu hükmü de, 647 s. Kanunun düzenlemesine nazaran lehe hükümdür. Bu durum karşısında, yeni TCK'nın yürürlük tarihinden önce işlenmiş olan suçlar dolayısıyla mahkûm olunan cezanın ertelenip ertelenemeyeceği sorunu değerlendirilirken, yeni TCK'nın düzenlemesi dikkate alınarak, failin daha önce üç aydan fazla süreli hapis cezasına mahkûm olmamış olmasını araştırmak gerekmektedir.

647 s. (mülga) İnfaz Kanunu hükümlerine göre, "ağır" veya "hafif" para cezası da ertelenebilmekteydi. Buna karşılık, yeni TCK'nın sisteminde ise, sadece hapis cezası ertelenebilecektir. Bu bakımdan, para cezalarının³⁴⁵ ertelenmesine

³⁴⁴ Yeni TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 4.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı Kanun tarafından, kanunlarda geçen "ağır hapis" cezaları hapis cezasına dönüştürülmüştür (m. 6).

³⁴⁵ Yeni TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 4.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı Kanun tarafından, kanunlarda geçen "ağır para" cezaları adli para cezasına dönüştürülmüştür (m. 5, f. 1).

de imkan tanıyan 647 s. Kanun hükümleri, yeni TCK'nın düzenlemesine nazaran lehe hüküm niteliği taşımaktadır.

765 s. (mülga) TCK hükümlerine göre, cezası ertelenen kişi, işlediği suç “cürüm” niteliğinde ise, beş yıl süreyle denetime tabi tutulmaktaydı. Bu bakımdan, söz konusu Kanun, maktu bir deneme süresi kabul etmişti (m. 95). Buna karşılık, yeni TCK'ya göre, “*cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir.*” (m. 51, f. 3). Keza, yeni TCK'ya göre, 765 s. Kanunun aksine, denetim süresi içinde hükümlüye belirli yükümlülükler yüklenebilecek ve hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilebilecektir (m. 51, f. 4–7). Bu bakımdan, 765 s. Kanun hükümleri, yeni TCK'nın düzenlemesine nazaran lehe hüküm niteliği taşımaktadır.

765 s. Kanun hükümlerine göre; cezası ertelenmiş olan mahkûmun deneme süresi içinde herhangi bir suç işlememesi durumunda, “*mahkûmiyeti esasen vaki olmamış*” sayılacaktı (m. 95). Buna karşılık, yeni TCK'ya göre, “*denetim süresi yükümlülüklerle uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.*” (m. 51, f. 8). Bu bakımdan, 765 s. Kanunun bu hükmü, yeni TCK'nın düzenlemesi karşısında lehe hüküm niteliği taşımaktadır.

Keza, yeni TCK'nın 7. maddesinin üçüncü fıkrasının uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki örnek olaylardaki çözüm şekillerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

ÖRNEK OLAY I: Belediye başkanı A'nın 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlemiş olduğu görevi kötüye kullanma suçundan dolayı hakkında, a) iki yıl hapis cezası, b) üç milyar lira ağır para cezası ve c) süresiz olarak memuriyetten yasaklılık cezasına hükmolunmuş ve bu cezaların ertelenmesine karar verilmiştir. 1 Haziran 2005 tarihine kadar deneme süresinin henüz bir yılı geçmiştir.

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra bu olayla ilgili olarak lehe kanunun belirlenmesi bağlamında yapılması gereken ilk iş, A'nın 765 s. TCK'nın 240. maddesine istinaden mahkûmiyetine neden olan olayın yeni TCK'nın 257. maddesine göre de suç oluşturup oluşturmadığının tespiti olacaktır.

Her iki kanunda da görevi kötüye kullanma suçu tanımına yer verilmiştir. Ancak, görevi kötüye kullanma suçundan dolayı cezaya hükmolunabilmesi için, 765 s. Kanundan farklı olarak, yeni TCK'nın sisteminde, görevin gereklerine aykırı fiilin, a) belli bir kişinin mağduriyetine veya b) kamunun zararına neden olması ya da c) bir kişiye haksız bir menfaat sağlaması gerekir; yani, bu objektif cezalandırılabilme şartlarından birinin, somut olayda gerçekleşmesi gerekir. 765 s. Kanun hükümlerine göre mahkûmiyeti gerektiren olayda 5237 s. TCK'nın aradığı objektif cezalandırılabilme şartlarından biri gerçekleşmemiş ise, fail ce-

zalandırılmaz. Bu durumda belediye başkanı A hakkında lehe olan yeni Kanun hükümleri gereğince beraat kararı verilmesi gerekir.

Buna karşılık, 765 s. Kanun hükümlerine göre mahkumiyeti gerektiren olayda 5237 s. TCK'nın aradığı objektif cezalandırılabilme şartlarından birisi gerçekleşmiş, örneğin görevin gereklerine aykırı fiil ile bir başkasına haksız bir çıkar sağlanmış olabilir. Bu durumda, cezası ertelenmiş olan A, deneme süresi içinde yeni bir suç işlemediği sürece, 765 ve 647 s. Kanunlar kişinin lehine sonuç doğurduğu için, bu dosyada yeni Kanun hükümlerini uygulamaya imkan bulunmamaktadır.

Ancak, A, 765 ve 647 s. Kanunlara göre cezası ertelenmiş olması dolayısıyla, yine bu Kanunlara göre deneme süresi beş yıl olarak düşünülmelidir. Bu deneme süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde mahkumiyet esasen vaki olmuş sayılacaktır.

A bu beş yıllık deneme süresi içinde yeni bir suç işlerse, hakkında verilen erteleme kararı kaldırılacaktır. Ancak, bu durumda mülga 765 ve 647 s. Kanunların mı yoksa yeni TCK'nın mı lehine sonuç doğurduğunu belirlemek üzere yeniden bir değerlendirme yapmak gerekecektir. Çünkü, 765 s. Kanun hükümlerine göre, fail hakkında, a) iki yıl hapis cezası, b) üç milyar lira ağır para cezası ve c) süresiz olarak memuriyetten yasaklılık cezasına hükmolunmuştur. Halbuki yeni TCK'nın 257. maddesinde, görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak sadece hapis cezası öngörülmüştür. Keza bu Kanunun sistemine göre kişi görevi kötüye kullanma suçundan dolayı mahkum olduğu cezayı çekinceye kadar 53. maddenin birinci fıkrasında sayılan hakları kullanmaktan yoksun kalacaktır. Ayrıca mahkeme, görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle suç işlediği için fail hakkında hapis cezasının infazından sonra da belli bir süre ("*hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar*") bir süreyle) kamu görevi üstlenmesinin yasaklanmasına da karar verebilir. Buna rağmen, yeni TCK'da görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak öngörülen yaptırımlar, somut olayda failin lehine sonuç doğuracak mahiyet arz etmektedir. Bu itibarla, deneme süresi içinde yeni bir suç işlemesi halinde, A hakkında bu görevi kötüye kullanma suçundan dolayı yeni TCK hükümlerine göre mahkumiyet kararı tesis etmek ve fakat hükmolunan hapis cezasının ertelenmesine karar vermemek gerekir.

ÖRNEK OLAY II: Hırsızlık suçundan mahkumiyeti bulunan A hakkında, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlediği ikinci suçtan dolayı, lehe hükümler içerdiği için 5237 s. TCK hükümlerine göre mahkumiyet hükmü kurulmuş ve dolayısıyla, bu Kanunun tekerrür hükümleri uygulanmıştır. Mahkumiyet hükmünde, 5237 s. TCK'nın 58. maddesinin yedinci fıkrasının gereği olarak, A hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Lehe kanunun belirlenmesinde karma uygulama yapılamayacaktır. Ancak çapraz uygulama mümkün olabilecektir. Şöyle ki, A hakkında 1 Haziran 2005 tari-

hinden önce işlediği suçtan dolayı hükmün kurulması aşamasında uygulanan düzenlemeleri bakımından lehine sonuç doğurduğu için yeni Kanunlar uygulanacaktır. Buna karşılık, hükmün infazı aşamasında özellikle koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için infaz kurumunda çekilmesi gereken süre bakımından 765 ve 647 s. Kanunların hükümleri kişinin lehinedir. Bu nedenle, hükmün infazı aşamasında A hakkında 765 ve 647 s. Kanunların koşullu salıverilmeye ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

Her ne kadar infaz rejimine ilişkin hükümler kural olarak derhal uygulanır ise de, 5237 s. TCK'nın 7. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince koşullu salıverilme ile ilgili olarak maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulama kuralları uygulanacaktır.

Buna karşılık, A hakkında koşullu salıverildikten ve hatta cezasının infazı tamamlandıktan sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır. Çünkü bir infaz rejimi olan denetimli serbestlik tedbiriyle ilgili kanuni hükümler bakımından derhal uygulama kuralına göre hareket etmek gerekir.

D. Geçici ve Süreli Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu

Yeni TCK'nın 7. maddesinin dördüncü fıkrası, geçici ve süreli kanunlarla ilgili zaman bakımından uygulamaya ilişkin bir hüküm içermektedir. Bu fıkranın gerekçesindeki yer verilen açıklamalar, bu hususa ilişkin tereddütleri giderme ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü açısından yeterli açıklıktadır³⁴⁶:

“Süreli ve geçici kanunların bu madde kapsamı içinde olmamasının, adalet, sosyal yarar ve kanunun etkinliği gereği bulunduğu kabul edildiğinden, son fıkra metinde yer verilmiş ve böylece süreli ve geçici kanunların etkinliğinin ve adaletin sağlanması istenilmiştir.

Bilindiği gibi bir kısım ceza kanunları, olağanüstü hâlleri ve geçici durumları karşılamak amacıyla ve dolayısıyla nitelikleri yönünden geçici olarak veya kanun metninde açıkça belirtilen süre kadar yürürlükte kalmak üzere meydana getirilirler. Bu tür kanunların, nitelikleri gereği, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş bütün suçlar hakkında uygulanmaları zorunludur. Aksi takdirde söz konusu kanunların caydırıcı etkileri kalmaz veya azalır. Oysa, çeşitli nedenlerle suçların failleri ele geçirilememekte ve örneğin iştirak hâlinde işlenen bir suçta kaçan fail, kanunun uygulama süresi geçtiğinde hiçbir yaptırım ile karşılaşmamaktadır. Bu nedenle maddenin son fıkrasıyla, bu maddenin geçici ve süreli kanunlar hakkında uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir. Zamanaşımı hükümleri ise, elbette ki, bu suçlar bakımından da geçerlidir.”

³⁴⁶ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 410.

E. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısı metninde zamanaşımına ilişkin hükümlerle ilgili zaman bakımından uygulama kuralları belirlenmişti (m. 12):

“Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında failin lehinde sonuç verecek kanunun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır.

Türk Ceza Kanununun dava veya ceza zamanaşımının durmasına ilişkin hükümleri ise Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında da uygulanır.”

1982 Anayasası, dava ve ceza zamanaşımına ilişkin kanun hükümlerinde değişiklik yapılması durumunda da, **maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulama kurallarının** geçerli olacağını kabul etmiştir (m. 38, f. 2)³⁴⁷.

Buna karşılık, (mülga) 765 s. Türk “*Ceza Kanununun Mevkii Mer’iyete Vaz’ına Müteallik Kanun*”, dava veya ceza zamanaşımına ilişkin süreler ile bu süreleri kesen veya durduran sebepler açısından bir ayırım yapmıştı (m. 22). Buna göre, dava veya ceza zamanaşımına ilişkin sürelerde değişiklik yapan sonraki kanun, lehe hükümler içeriyorsa, geçmişe etkili olarak uygulanacaktır. Sonradan yürürlüğe giren kanun, zamanaşımını kesen veya durduran sebeplerle ilgili olarak bir değişiklik yapmışsa, lehe veya aleyhe olmasına bakılmaksızın, derhal uygulanabilmekteydi³⁴⁸.

Kanımızca, gerek dava gerek ceza zamanaşımına ilişkin sürelerle, bu süreleri kesen veya durduran sebeplerle ilgili kanun değişikliklerini **maddi ceza hukukuna** ilişkin değişiklikler olarak nitelendirmek ve bu çerçevede çözümler üretmek gerekir³⁴⁹.

³⁴⁷ Zamanaşımına ilişkin hükümler açısından Anayasadaki düzenlemeye paralel görüş için bkz. ARTUK, Ceza Hukuku El Kitabı, sh. 146.

³⁴⁸ İÇEL/DONAY(3) sh. 96/97; ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 166 vd.

³⁴⁹ Buna karşılık, **usul hukukunda** ise, bazı istisnai haller dışında, sonradan yürürlüğe giren kanunun lehte veya aleyhte hükümler içerdiğine bakılmaksızın **derhal uygulama** kuralı geçerlidir.

Usul hukukuna ilişkin kanun değişikliklerinin zaman bakımından uygulanması açısından diktik nitelik taşıyan Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**’nun şu kararını naklediyoruz:

«Usul hukukunda **genel ilke**, olay ve işlemlerin o sırada yürürlükte bulunan Hukuk kurallarının uygulanmasına “**hemen uygulama**” (**derhal uygulama**) ilkesi denilmektedir. Bir olay veya işleme daha sonra yürürlüğe giren bir hukuk kuralının uygulanması ise istisnayı oluşturur. Sonradan yürürlüğe giren kuralın uygulanmasına ise, “geçmişe yürüme” ilkesi denilmektedir. Geçmişe yürüme esasen bir istisnadır. Ceza Yasası veya ceza hükmü taşıyan özel yasalarda yapılan değişiklikler eğer sanık lehine iseler, (mülga 765 s.) TCK’nın 2/2. maddesi uyarınca yeni yasa uygulanacaktır. Muhakeme Kanunlarında yapılan değişiklikler ise, derhal uygulanmaya başlarlar. Bu değişikliklerin sanık lehine olup olmaması önemli değildir. Esasen derhal uygulama ilkesi yeni yasanın eskisinden daha mükemmel olması ve ülkede aynı anda iki muhakeme kanununun uygulanması ve kanunların yürürlükte bulundukları süre içinde düzenlendikleri sahalarda uygulanması gerektiği ilkesine dayanmaktadır.

Böylece, Muhakeme Kanunlarında derhal uygulama ilkesinin duraksamaya yer vermeyecek biçimde geçerli olduğu belirlenmiş bulunmaktadır. Bu ilkeye bağlı kalınarak eski muhakeme ka-

Nitekim, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 1982 Anayasası, dava ve ceza zamanaşımına ilişkin kanun hükümlerinde değişiklik yapılması durumunda da, **maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulama kurallarının** geçerli olacağını kabul etmiştir (m. 38, f. 2). Bu nedenle, yeni TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında “*Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin kurallar göz önünde bulundurularak; Tasarının, zamanaşımına ilişkin hükümlerin zaman bakımından uygulanmasına ilişkin 12'nci maddesi metinden çıkarılmıştır.*”³⁵⁰.

nunu zamanındaki işlemler eski kanuna göre sonuçlandırılmalıdır. Yeni kanun ise, yürürlüğe girdikten sonraki işlemlere uygulanmalıdır. Böylece, yeni kanunun geçmişe yürüyemeyeceği kabul edilmelidir. Yeni kanunun geçmişe yürüyemeyeceği ilkesinin doğal sonucu olarak eski kanun zamanında yapılıp tamamlanmış işlemler geçerliliklerini korumakta ve yenilenmemektedir.

O halde derhal uygulama ilkesinin sonucu olarak;

- a) Usul işlemlerinin mutlaka yürürlükteki muhakeme kanunlarına göre yapılacağı,*
 - b) Yürürlükteki muhakeme kanununa uygun olarak yapılan işlemlerin sonradan değiştirilen muhakeme kanunu uyarınca geçerliliğini kaybetmeyeceği,*
 - c) Yeni muhakeme kanununun yürürlüğe girmesinden sonra yapılması gereken usul işlemlerinin yeni kanuna tabi olacağı,*
 - d) Yeni muhakeme kanununun uygulanmasında yeni düzenlemelerin sanığın leh veya aleyhinde olmasına bakılmayacağı,*
- ... sonuçları çıkar.*

Ancak, derhal uygulama ilkesinin geçerli olmadığı hallerin varlığı da söz konusu olabilmektedir. Şöyle ki; sırf üst dereceli mahkemenin iş yoğunluğunu azaltmak için kabul olunan görev normlarının üst dereceli mahkemede açılmış davalarda hatta duruşma başlamadan da olsa, derhal uygulanmaması yürürlükten kalkın normun uygulanmasına devam edilmesi, uygulamanın devamlı olmayacağı ve görevsizlik kararıyla işler uzayacağı için, geçici maddelerle kabul olunabilir. Örneğin 2248 sayılı Yasanın geçici 1. maddesiyle bu yol izlenmiştir.

Keza; derhal uygulama ilkesi bazen haksız sonuçların doğmasına da yol açabilir. Meselâ eski kanuna göre kanun yoluna başvuran için daha uzun bir süre tanınmış iken, yeni kanun bu süreyi kısaltmış olabilir. Yeni kanunun, kanun yoluna başvuru için öngörülen süreyi kısaltması durumunda eski kanunun zamanında daha süresi olduğu düşüncesiyle bekleyip kanun yoluna başvurmamış olanlara uygulayarak önceki kanuna göre düşmemiş olan “kanun yoluna başvurma hakkı”nı bu gibi kimselere tanımamak haksızlık olacağından, yeni kanunu derhal uygulamamak gerekir. Bu gibi durumlar yeni kanunun derhal uygulanması ilkesinin istisnalarını oluşturur.

Ancak, eski kanunun bir usul işleminin yapılması için öngördüğü süreden fazla bir süre aynı usul işlemi için yeni kanunda benimsendiği takdirde, durum yeni kanunun derhal uygulanırlığı ilkesine göre çözümlenmelidir. Şöyle ki; eski kanun zamanında o usul işlemi için bir haftalık süre öngörmüş iken, bu süre içerisinde usul işlemi yerine getirilmemişse, yeni kanun bunu 15 güne çıkarmış olsa bile, yeni kanuna göre yapılacak bir işlem kalmamıştır. O usul işlemi ile ilgili iş eski kanuna göre ölmüştür. Yeni kanun onu diriltmez; ancak, eski kanunda öngörülen bir haftalık süre dolmadan yeni kanun yürürlüğe girseydi, ilgili kişi 15 günlük süreden yararlanabilecekti. Eğer eski kanun 15 gün süre vermişken yeni kanun bunu bir haftaya indirseydi, sürenin başlangıcından itibaren bir hafta geçmemişse, işlem yeni kanuna tabi olacak; sürenin başlangıcından itibaren bir hafta geçmişse, yeni kanun uyarınca işlem yapılamaz hale girecektir. Demek ki, derhal uygulanırlık, ilke olmakla beraber; bu ilkenin haksızlıklara sebebiyet vermesi halinde kabul edilebilen istisnaları vardır.»: CGK., 12.4.1993, 6-62/94 (YKD, Ağustos 1993, sh. 1226 vd.). Ayrıca, bkz. CGK., 15.3.1993, 7-314/67 (YKD, Eylül 1993, sh. 1394 vd.); CGK., 15.3.1993, 5-15/62 (YKD, Mayıs 1993, sh. 760 vd.).

³⁵⁰ TBMM Adalet Komisyonunun, yeni TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin 3.11.2004 tarihli ve Esas 1/592, Karar 64 sayılı Raporu, (TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 675).

F. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Etki Alanı ve Uygulaması

İşlendiği tarihteki kanunlara göre suç teşkil eden bir fiil sonradan yürürlüğe giren yeni kanunla suç olmaktan çıkarılmış ya da suçun unsurlarında veya cezasında failin lehine değişiklikler yapılmış ise; fail hakkında bu yeni kanun hükümleri uygulanacaktır.³⁵¹

Lehe olan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve fakat henüz kesinleşmemiş olan mahkûmiyet kararları hakkında da uygulama kabiliyeti bulacağı konusunda fikir birliği mevcuttur.

Ancak, lehe olan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiillerle ilgili olarak verilmiş olan hüküm kesinleşmiş ise, lehe olan kanunun bu kesinleşmiş kararlar üzerinde bir etkisinin olup olmadığı tartışma konusu olmuştur.

Bir görüşe göre, lehe olan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş olan kararlar üzerinde herhangi bir etkisi olamaz.³⁵²

Buna karşılık, TCK'da kabul edilen sisteme göre; lehe olan kanun, yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş mahkûmiyet kararları hakkında, ceza infaz edilmiş olsa bile, uygulama kabiliyetini haiz olacaktır.³⁵³ 1982 Anayasasında, zaman bakımından uygulamaya ilişkin ilkelerin ceza mahkûmiyetinin kanuni

³⁵¹ Önceden işlenmiş olan fiil dolayısıyla ceza davası devam etmekte iken sonradan yürürlüğe giren kanunla suç olmaktan çıkarılmış ise; fail hakkında **beraat** kararı verilmesi gerekir (ARTUK, Ders notları, sh. 128). Yargıtay'ın içtihadı da bu yöndedir:

«TCK'nın 2. maddesinin(e) ... göre, kanunlar yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren uygulama alanı bulurlar. Ceza Hukukunda failin lehine olan kanunların geçmişe uygulanırlığına karşılık; failin durumunu ağırlaştıran kanunlar geçmişe uygulanamazlar. Bu itibarla, ...

a) İşlendiği zaman ... suç sayıl(may)an bir fiilin, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla suç sayılmış olması halinde fail.. cezalandırılmayacaktır).

b) İşlendiği zaman ... suç sayılan bir fiil, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla suç olmaktan çıkarılmış veya sonradan yürürlüğe giren ... kanun suçun işlendiği zamanın kanununa göre suçlunun lehine ise, sonraki kanun.. önceden işlenmiş fiillere uygulanacaktır).

Sonraki kanun ile suçun yürürlükten kaldırılmasının sonucu olarak; 1) Önceki kanun zamanında işlenmiş fiiller, sonraki kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkmış ise, fail hakkında ceza takibatında bulunulamaz. 2) Mahkûmiyet (kararı) kesinleşmiş ise, sonraki kanunun yürürlüğe girmesi ile, (cezanın infazına henüz başlanmamışsa, artık infaz edilmez; infazına başlanmış ise, infaza son verilir). 3) Fail hakkında Kamu Davası sürmekte iken sonraki kanun yürürlüğe girmiş ise, ne yapılmalıdır?

TCK'nın 163. maddesindeki fiiller (3713 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu"nın 23/c maddesi ile) suç olmaktan çıkarılmış bulun(ul)masına ... göre; (inceleme konusu olayda) fail hakkında sabit görülen fiil, sonradan yürürlüğe giren kanun ile suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu durumda fail hakkında) **beraat kararı** verilmesi gerekir. (Not: Bir üye, bu durumda "Kamu Davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi" gerektiği gerekçesiyle, söz konusu Karara muhalif kalmıştır.): CGK, 15.5.1991, 9-79/148 (YKD, Temmuz 1991, sh. 1088 vd.). Aynı mealde 9.CD, 23.9.1994, 3797, 4999 (YKD, Ocak 1995, sh. 140 vd.).

³⁵² İÇEL/DONAY(3), sh. 98.

³⁵³ EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 149; ARTUK, Ders Notları, sh. 129; aynı yazar, Ceza Hukuku El Kitabı, sh. 139.

neticeleri bakımından da uygulama kabiliyetine sahip olduğunun ifade edilmesiyle (m. 38, f. 2), aynı sistem benimsenmiştir.³⁵⁴

Mülga 765 s. Kanunda (m. 2, f. 1) olduğu gibi, yeni TCK'daki ifadeye göre, lehe olan kanun “*kendiliğinden*” geçmişe etkili olacaktır (m. 7, f. 1). Bu ifade, lehe olan kanunun *ayrıca yargı kararına gerek olmadan* geçmişe etkili olacağı şeklinde anlaşılmaktadır.³⁵⁵ Suç teşkil eden bir fiilin sonradan yürürlüğe giren bir kanunla suç olmaktan çıkarılması durumunda, lehe olan bu kanunun geçmişe uygulanması sorun teşkil etmemektedir. Ancak, lehe olan kanunun geçmişe uygulanması çoğu zaman yargısal bir değerlendirmeyi ve dolayısıyla bir yargı kararını gerekli kılmaktadır.³⁵⁶ Bu nedenle, 765 s. Kanunun ifade biçiminin etkisiyle yeni TCK’nın 7. maddesinin birinci fıkrasında geçen “*kendiliğinden*” ibaresinin metinden çıkarılması yerinde olacaktır.³⁵⁷

G. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu

Bir fiili suç olarak tanımlayan kanun hükmüyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin bilahare iptal kararı vermesi durumunda bu kararın etkisi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Anayasa’ya göre; Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kanun hükümleri kural olarak “*iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırılabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.*” (m. 153, f. 3). Ayrıca, “*iptal kararları geriye yürümez.*” (m. 153, f. 5).

Anayasa Mahkemesi, 765 s. (mülga) TCK’nın “*erkeğin zinası*” suçunu tanımlayan 441. maddesini, “*karının zinası*” suçunu tanımlayan 440. madde hükmü karşısında eşitsizliğe sebebiyet verdiği gerekçesiyle iptal etmişti.³⁵⁸ Ancak, Yüksek Mahkeme, 441. madde hükmünü iptal ederken, bu iptalin ortaya çıkara-acağı kanun boşluğunun oluşturacağı sakıncaları gözönünde bulundurarak; iptal

³⁵⁴ 1930 İtalyan Ceza kanununda kabul edilen (m. 2, f. 2, 3) diğer bir sisteme göre, sonradan yürürlüğe giren lehe kanun, önceden işlenmiş fiili suç olmaktan çıkarıyorsa, kesinleşmiş hükümler üzerinde de etkili olmaktadır. Buna karşılık, sonradan yürürlüğe giren kanun, fiili suç olmaktan çıkarmamakla birlikte, failin lehine sonuçlar doğuran hükümler içermekte ise, artık bunun kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararları üzerinde bir etkisinden söz edilemez (Bkz. ARTUK, Ders Notları, sh. 129; aynı yazar, Ceza Hukuku El Kitabı, sh. 139).

³⁵⁵ ARTUK, Ders Notları, sh. 130; aynı yazar, Ceza Hukuku El Kitabı, sh. 139; ayrıca bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 139.

³⁵⁶ İÇEL/DONAY(3), sh. 98, dn. 92.

³⁵⁷ Maddeye ilişkin müzakereler sırasında TBMM Adalet Alt Komisyonunda gündeme getirmemize rağmen, bu düşüncemiz, Komisyon tarafından kabul görmemiştir.

³⁵⁸ Anayasa Mahkemesi, 23.9.1996, 15/34 (RG: 27 Aralık 1996/22860, sh. 246 vd.).

kararının, Resmi Gazetede yayınlanacağı tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe gireceğini karara bağlamıştı. Söz konusu karar, 27.12.1996 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olmakla, 27.12.1997 tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu tarihe kadar da TBMM’nde “*erkeğin zinası*” fiilini suç olarak tanımlayan yeni bir kanun kabul edilmediği için, bu fiil artık suç olmaktan çıkmıştır³⁵⁹.

Bu durumda ortaya şöyle bir sorun çıkmıştı: 27.12.1997 tarihinden önce işlenmiş olan “*erkeğin zinası*” suçundan dolayı açılan bir kamu davası sonuçlanmadan Anayasa Mahkemesi’nin sözünü ettiğimiz kararı yürürlüğe girdi. “*Erkeğin zinası*” fiili suç olmaktan çıkarılmış olmasına rağmen, bu kamu davasında faili cezalandırabilecek miyiz?

Yargıtay, Anayasa’nın 153. maddesi hükmüne rağmen, çok zorlama bir yorumla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararını geriye yürüterek, dava konusu olayda failin cezalandırılmaması gerektiği sonucuna ulaşmıştı³⁶⁰.

Kanımızca, Anayasa’nın 153. maddesi hükümleri karşısında, bu sonuca ulaşmak hukuken mümkün görülmemektedir.

Bu sorunun çözümlenebilmesi için, kanımızca, Anayasanın 153. maddesinin 5. fıkrasının değiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu itibarla, bu fıkra hükmü şu şekilde formüle edilebilir:

“İptal kararları geriye yürümez. Ancak, bir suçun unsurlarına, sair cezalandırılabilme şartlarına, cezasına, ceza mahkumiyetinin kanuni neticelerine ilişkin kanun hükümlerinin iptali halinde; lehe sonuç doğuran iptal kararları, geriye etkili olur”^{361 362}.

³⁵⁹ Bu iptal kararının ortaya çıkardığı kanun boşluğu TBMM tarafından doldurulmadığı için; Anayasa Mahkemesi, bu defa, TCK’da “*karının zinası*” suçunu tanımlayan 440. madde hükmünü yine eşitliğe aykırı bularak iptal etti: Anayasa Mahkemesi, 23.6.1998, 3/28 (RG: 13 Mart 1999/23638).

³⁶⁰ 5. CD., 9.3.1998, 82/854 (YKD, Mart 1998, sh. 456 vd.).

³⁶¹ Ayrıca bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler (10), sh. 75; KANGAL, Zeynel T.: *Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması*, in: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010/1, cilt I, sh. 807.

³⁶² Anayasa Mahkemesi, Kabahatler Kanunu’na 2.7.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (m. 20) ile eklenen kabahat tanımını (m. 42/A) suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırılık dolayısıyla iptal etmiştir (7.12.2023, E. 2018/117, K. 2023/212, pn. 161 ilâ 165). Bu iptal kararı, gerekçesi ve sonucu itibarıyla doğrudur. Ancak, Anayasa Mahkemesi, ayrıca bu iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 4.6.2024 tarihinden itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Bu iptalin yürürlük tarihine ilişkin karar, **Anayasa’ya aykırıdır** ve hukuken hiçbir anlam ifade etmez.

Bu iptal kararı üzerine, iptal edilen hükümdeki kabahat tanımına uygun fiiller, yeni bir kanuni düzenleme yapıncaya kadar kabahat veya suç olarak nitelendirilemez. Hatta iptal edilen hükümdeki kabahat tanımına uygun fiil söz konusu iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten önce işlenmiş olsa bile, bu iptal kararı üzerine artık bu kabahat hükmüne istinaden yaptırım uygulanamaz. Ancak, iptal edilen hükümdeki kabahat tanımına uygun fiil dolayısıyla faili hakkında verilmiş olan idari para cezası kararı söz konusu iptal kararının Resmi Gazetede

H. Kabahatlerle İlgili Zaman Bakımından Uygulama Kuralları

5326 sayılı *Kabahatler Kanununun* 5. maddesinde kabahatlerde zaman bakımından uygulamaya ilişkin özel bir düzenleme yapılmıştır:

“(1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idari yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.

(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.”

Bu maddenin **gerekçesi** şu şekildedir:

“Maddenin birinci fıkrasında, zaman bakımından uygulama ile ilgili olarak yeni Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümlerinin kabahatler bakımından da uygulanabileceği vurgulanmıştır. Ancak, idari yaptırımların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı kabul edilmiştir.

İkinci fıkrada, zaman bakımından uygulama kurallarının uygulanmasıyla ilgili sınırlayıcı bir hükme yer verilmiştir. Buna göre, kabahatin ne zaman işlendiğini belirleme açısından, neticenin meydana geldiği zaman değil, münhasıran fiilin gerçekleştiği zaman dikkate alınmalıdır.”³⁶³

yayımlandığı tarihten önce yerine getirilmiş ise, idari para cezası olarak ödenmiş olan para iade edilmez.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kabahat tanımına ilişkin hükmün iptaline karar verdikten sonra, bu kararın ileri bir tarihte yürürlüğe girmesi yönünde ayrıca bir karar vermiş olsa bile, bu zaman zarfında, yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı takdirde, iptal edilen kabahat tanımına uygun fiiller dolayısıyla artık idari para cezası kararı verilemez. İptal edilen madde metnindeki tanıma uygun fiilin bilahare kabahat veya suç olarak tanımlanmasına yönelik yeni bir kanuni düzenleme yapıldığı takdirde, ancak bu kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işlenen fiil, suç veya kabahat olarak yaptırım uygulanmasını gerektirir.

³⁶³ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840.

§11. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı

I. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Yer Bakımından Uygulanması

Türkiye’de yayınlanan Ceza Hukuku Genel Hükümler ders kitaplarında milletlerarası ceza hukukuna ilişkin pek çok konu, ceza kanununun yer bakımından uygulamasıyla bağlantılı olarak açıklanmaktadır. Ceza hukukuna ilişkin pek çok kavram henüz izah edilmeden milletlerarası ceza hukukuna ilişkin açıklamada bulunulmasını doğru bulmamaktayız. Biz, kitabımızın dördüncü bölümünde milletlerarası ceza hukukuna ilişkin açıklama yapacağız.

II. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulanması

Türkiye’de yayınlanan Ceza Hukuku Genel Hükümler ders kitaplarında ceza kanununun kişi bakımından uygulama alanıyla bağlantılı olarak Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu, milletvekili dokunulmazlığı, diplomasi dokunulmazlığı ve ayrıca yabancı asker kişilerin ceza sorumluluğu gibi konular işlenmektedir. Biz, bu başlık altında incelenen konuların her biri ile ilgili olarak, farklı nitelik taşımaları dolayısıyla, Suç Teorisine ve milletlerarası ceza hukukuna ilişkin bölümlerde yeri geldiğinde açıklama yapmanın daha doğru olacağını düşünmekteyiz.

İkinci Bölüm SUÇ TEORİSİ

§12. Suçun Yapısını Açıklayan Teoriler

I. Klasik Suç Teorisi

19. yüzyıl Kara Avrupasında ceza hukukuna hakim olan düşünce, nedensellik bağlantısı merkezli klasik suç teorisidir¹.

Klasik suç teorisinin esasını, *hareket* kavramı oluşturmaktadır. Söz konusu teoriye göre, kanunî tanıma uygun (“tipik”) netice, fiilin bir parçasını oluşturmaktadır. Geniş anlamda hareket, yani fiil; dar anlamda hareket ve neticeden oluşmaktadır. Yani, netice, fiilin bir unsuru olarak mütalâa edilmektedir². Bu iki unsur, birbirleriyle nedensellik (illiyet) bağıyla bağlantılı bulunmaktadır.

Bu teori taraftarlarınca suçun tanımı şu şekilde yapılmıştır: “*Suç, kanunî tarife (tipe) uygun, hukuka aykırı ve kusurlu bir harekettir*”³.

Bir şeyin istenmiş olması yeterlidir; fakat, neyin irade edildiği, hareket kavramı açısından önemsizdir⁴. Söz konusu teori, neticenin gerçekleşmesini, esas telâkki etmektedir. Böylece, objektif (maddi) haksızlık kıstasını, netice oluşturmaktadır.

Hareket, kanunî tarife uygun neticenin gerçekleşmesini sağlayan bir illî etkileşimdir. Hareket kavramı, ontik, hukuka takaddüm eden ve değerden yoksun bir kavramdır.

Bütün tabîî vakıalar gibi, suç da bir illî etkileşim serisinin sonucudur. Fakat, kanunî tarife uygun (“tipik”) neticenin oluşumuna sebebiyet veren bu illî faktörler arasında bir sınırlama yapmak gerekir:

Bir kısım yazarlara göre; bu neticenin oluşumuna doğrudan etkide bulunan ve ceza hukuku açısından önem arzeden illî faktörler dikkate alınacaktır (“*Adaequanztheorie*”, **Uygunluk teorisi**)⁵.

¹ Bu teorier hakkında bilgi için ayrıca bkz. ÇINAR, İsmail: *Ceza Hukukunda Ön Kusurluluk*, Ankara 2024, sh. 23 vd.

Bu görüşe eleştiri için bkz. JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 194.

² Aynı şekilde, Türk hukukunda hareket ve netice, birlikte fiili oluşturmaktadır: DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku*, Cilt I, 10. Bası, 1987, no. 502; KUNTER, Nurullah: *Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi (Hareket - Netice - Sebebiyet Alâkası)*, İstanbul, 1954, sh. 8; EREM, Faruk: *Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Genel Hükmüler*, cilt I, 12. bası, 1984, § 10; ALACAKAPTAN, Uğur: *Suçun Unsurları*, 1975, sh. 39; HAKERİ, Hakan: *Ceza Hukuku*, 5. bası, Ankara, Ocak 2007, sh. 114.

³ BELING, Ernst: *Die Lehre vom Verbrechen*, 1906, sh. 7; v.LISZT, Franz: *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, 14/15. Auflage, 1905, sh. 117.

⁴ BELING, Die Lehre vom Verbrechen, sh. 9 vd.; v.LISZT, Lehrbuch(14/15), sh. 122.

Yine, bir kısım yazarlara göre, neticenin oluşumuna etkide bulunan illi faktörler eşdeğerdedir. Bunlar arasında yapılacak sınırlama failin sübjektif (manevi) durumu dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır (“Äquivalenztheorie”, **Eşdeğerlilik teorisi**)⁶.

Klasik suç teorisine göre, suçun kurucu unsurları maddi (objektif) ve manevi (sübjektif) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kanunî tarife uygunluk (tipiklik) ve hukuka aykırılık unsuru, sübjektif unsurlardan arındırılmış olup, tamamen objektif karakter arzotmektedirler⁷.

Kanunî tarife uygunluk (tipiklik), bir insan davranışının haricî görünümünün kanunen tanımlanmasından ibaret olup, herhangi bir değerden yoksundur⁸. Bir fiile değer izafesi, ilk defa hukuka aykırılığa ilişkin tetkikte ve fakat, yine yalın objektif bir bakış açısıyla yapılacaktır. Örneğin, bir insanın öldürölmesi olayında, ancak bir hukuka uygunluk sebebinin var olup olmadığı hususunda yapılacak olan araştırmayla, fiilin hukuk düzenince tasvip edilip edilmediği anlaşılacak, başka bir ifadeyle, değer(sizlik) ifade edecektir⁹. Kanunî tarife uygunluk, hukuka aykırılığın emaresini teşkil edecektir¹⁰.

Buna karşılık, kusur ise, tamamen sübjektif (manevi) bir yapıya sahiptir. Kusura ilişkin tetkikte failin fiili işlerken içinde bulunduğı ruhî, psikolojik durum araştırılacaktır. Bu kusur anlayışında, “isnat yeteneğı” *kusurluluğun* bir *önşartı* olarak telakki edilmektedir¹¹. Kast ve taksir, iki *kusurluluk şekli* olarak öngöröl-mektedir. Zorunluluk (zaruret, ıztırar) hali ise, kusurluluğı kaldıran bir sebep

⁵ HORN, Arnold: *Causalitäts- und Wirkungsbegriff, dessen empirische und kriminalrechtliche Bedeutung*, GS 54(1897), 351 vd. Bu konuda fikir için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Suçta İştirakin Hukuki Esası ve Faillik*, 1996, sh. 45 vd.

⁶ v.BURI, Maximilian: *Über Causalität und deren Verantwortung*, 1873, sh. 2 vd.; aynı yazar, *Die Causalität und ihre strafrechtliche Beziehungen*, 1885, sh. 1 vd. Bu teori, bugün dahi Alman hukukunda çoğunluk tarafından kabul edilmektedir: WELZEL, Hans: *Das deutsche Strafrecht*, 11. Auflage, 1969, sh. 46; MAURACH, Reinhart/ZIPF, Heinz: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, Teilband I, 7. Auflage, 1987, sh. 245 vd.; STRATENWERTH, Günter: *Strafrecht, Allgemeiner Teil I. Die Straftat*, 3. Auflage, 1981, kn. 218; BAUMANN, Jürgen/WEBER, Ulrich/MITSCH, Wolfgang: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch*, 10. Auflage, 1995, § 14, kn. 8 vd.; JESCHECK, Hans Heinrich: *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, 1988, sh. 252 vd.

⁷ Aynı şekilde, Türk hukukunda ÖNDER, Ayhan: *Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Suç Genel Teorisi, Suçun Özel Belirliş Şekilleri*, cilt II, 1989, sh. 173 vd.; DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku*, cilt II, 9. Bası, 1986, no. 672, 696; TOROSLU, Nevzat: *Ceza Hukuku*, 2. bası, Ankara, Mart 1991, sh. 77.

⁸ BELING, Die Lehre vom Verbrechen, sh. 147, 178 vd.; aynı yazar: *Grundzüge des Strafrechts*, 11. Auflage, 1930, sh. 31; v.LISZT, Lehrbuch(14/15), sh. 140.

⁹ BELING, Die Lehre vom Verbrechen, sh. 178 vd.

¹⁰ CLASS, Wilhelm: *Grenze des Tatbestands*, 1933, sh. 39 vd.

¹¹ Aynı şekilde, ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 251 vd.; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 843 vd.

olarak anlaşılmaktadır¹². İşlediği fiilin bir haksızlık teşkil ettiği, hukuka aykırı olduğu konusundaki bilincin kişide bulunması gerekip gerekmediği, bu teoriye mensup yazarlar arasında görüş ayrılığına sebebiyet vermiştir. Meselâ, *Belting*, bu bilinci kusur açısından zorunlu görürken¹³; v.*Liszt*, söz konusu bilincin varlığını gerekli bulmamaktadır¹⁴.

Klasik suç teorisi bir değerden yoksun fiil kavramını esas almaktadır. Halbuki değerden yoksun bir fiilden hukuk alanında bahsetmek mümkün değildir. İhmalî suçlar dikkate alınır; klasik suç teorisinin fiilin normatif (değerlendirilebilir) özelliğini inkârı, ceza hukukunun müşahhas ödevlerine muvafık düşmemektedir¹⁵.

Yine, illî oluşumun tabîî olaylara paralel olarak izahı, ihmalî suçlarda başarısız olmuştur. Zira, ihmalî suçlarda tabîî anlamda bir illiyet ilişkisinin varlığından bahsedilemez. Bu nedenledir ki, söz konusu teori taraftarları, ihmalî suçlarda tabîî anlamda bir illiyet bağına aramamakta, yorum yoluyla böyle bir bağı varlığını kabul etmektedir¹⁶. Bu suçlara ilişkin kanunî tanımların karşıt anlamından (mefhumi muhalifinden) anlaşılacağı gibi; kişiden hukuk düzeninin gereği olarak belli bir davranışta bulunması beklenmektedir¹⁷. Fakat, bu izahla, hareketin tabîî özelliğinden sarfınazar edilmektedir¹⁸.

Klasik suç teorisi, neticeyi fiil içinde mütalaa etmektedir. Suç teorisine ilişkin bir çok münferit problemin, hareketle neticenin birbirinden ayrılması suretiyle, bir başka ifadeyle, suçun haksızlık muhtevasının hareketin ve neticenin ifade ettiği değersizlikle izah edilmesi karşısında; klasik suç teorisinin neticeye fiil içinde yer vermesi, bu münferit problemlerin izahını güçleştirmektedir¹⁹.

Taksirli suçlarda, gerçekleşen neticeye icra edilen hareket sebebiyet vermiştir. Fakat, hareket için kurucu unsur olan irade, bu neticeyi ihata etmemektedir. Bu nedenledir ki, klasik suç teorisine mensup yazarlarca, kasdî ve taksirli suçlar için müşterek bir hareket kavramı oluşturabilmek için, hareket açısından zarurî olarak aranan iradenin neye yönelik olduğunun araştırılmasından sarfınazar edilmiş, mücerret bir iradeyle iktifa edilmiştir. Ayrıca, fiil kavramı içinde iradî hareketle bunun sebebiyet verdiği netice birleştirilmiş bulunmaktadır. Böylece, taksirli suçlarda, hareket açısından yönlendirici olan irade tarafından ihata edilmemekle beraber, gerçekleşen netice de, fiile dahil edilmektedir. Fakat, bu

¹² v.LISZT, Franz: *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, 1. Auflage, 1881, sh. 105 vd.

¹³ BELING, Die Lehre vom Verbrechen, sh. 180 vd.

¹⁴ v.LISZT, Lehrbuch(1), sh. 109.

¹⁵ MAURACH/ZIPF I, sh. 194.

¹⁶ v.LISZT, Lehrbuch(15), sh. 132.

¹⁷ v.LISZT, Lehrbuch(4), sh. 141.

¹⁸ JESCHECK, Lehrbuch(4), 191, sh. 197; MAURACH/ZIPF I, sh. 194.

¹⁹ MAURACH/ZIPF I, sh. 195.

suretle hareket kavramına sadece belli neticelerin oluşumuna sebebiyet veren bir illî fonksiyon izafe edilmiş olmaktadır; ki bu, realiteyle bağdaşmaz²⁰.

Her ne kadar doğrudan veya kanunî tarife uygun illî etki gibi ya da sübjektif kıstaslarla bir sınırlamaya gidilmekteyse de; illî hareket kavramının alanı aşırı ölçüde genişletilebilmektedir. Şöyle ki, katili doğuran ananın doğum ameliyesi ya da katilin kullandığı silahı yapan ustanın bu fiili de illî hareket kavramı içinde mütalaa edilebilmektedir²¹.

Klasik suç teorisi tamamen objektif, maddi bir haksızlık unsuru öngörmektedir. Suçun haksızlık unsuru içinde sübjektif unsurlara yer verilmemektedir. Teorinin bu tutarsızlığı, kanunun münferit hukuka uygunluk sebepleriyle alakalı olarak, failin bu sebebin varlığının bilinciyle hareket etmesini aramasıyla aşılma istenmiştir²².

Her ne kadar kusurun sadece sübjektif unsurlardan oluştuğu savunulmaktaysa da; klasik suç teorisinden yana olan yazarlar da, bir “kusur şekli” olarak kabul ettikleri taksiri izah ederken, sadece sübjektif verilerle iktifa etmeyip, normatif değerlendirmelere de müracaat etmek zorunda kalmaktadırlar^{23,24}.

²⁰ MAURACH/ZIPF I, sh. 196.

²¹ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 198. Bu eleştirilerden kurtuluş çabaları için bkz. aynı sahife, dn. 10.

²² DÖNMEZER/ERMAN II, no. 699.

²³ Nitekim, *Dönmezer/Erman* da; kasden işlenen suçlar açısından “psikolojik kusur teorisi”ni kabul etmekle beraber; taksirle işlenen suçlar açısından “normatif kusur teorisi”nin de benimsendiği “kaynaştırıcı bir metod”la; klasik suç teorisini izlemişlerdir (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 912; aynı şekilde İÇEL, Kayıhan: *Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk*, 1967, sh. 16-17.

²⁴ Klasik suç teorisinin etkisindeki Yargıtay’ın kusur hakkındaki görüşleri şu kararda hülasa edilmiştir:

«Ceza Hukukunda ilke, *iradiliktir*. Bu itibarla, *iradî olmayan bir fiil hukuka aykırı olsa da, suç teşkil etmez*. Suçun bu niteliğine öğretide *manevî unsur* denilmektedir. Suçta manevî unsurun aranması ve bu unsur bulunmadıkça bir *fiilin* suç olamayacağının kabul edilmesi (gerekir.) ... (B)ir kimsenin cezalandırılması için tipe uygun ve hukuka aykırı hareket yetmemekte, aynı zamanda bu hareketin yapana *şahsen isnad* edilmesi, onun *hareketi hakkında bir değer hükmü* verilebilmesi de aranmaktadır.

Ancak, suçta manevî unsurun varlığından sözedilmek için, failin kusurlu bir şekilde hareket etmeğe ehil olması, hakeretin ona isnad edilebilmesi için gerekli kişisel niteliklerin bulunması gerekir. Kusurlu şekilde hareket etmeye ehil olmayan bir kişi, kusurlu hareket edemez. Bu itibarla *manevî unsur iki kısma ayrılmakta*, bunlardan birincisi failin kusurlu bir şekilde hareket etmeye ehil olması, ikincisi ise somut olayda kusurlu hareket etmiş bulunmasıdır. Bunlardan biricisine *isnad yeteneği*, ikincisine *kusurluluk* denilmektedir.

İsnad yeteneğini, bir fiilin bir kimsenin üstüne atılabilmesi, ona yüklenebilmesi için failde bulunması gereken niteliklerin tümü (olarak); bir başka deyişle, anlayabilme ve isteyebilme gücü olarak tanımlamak mümkündür. Bu unsur, fiilin unsuru değil, failin kişisel niteliklerini ilgilendirir bir kavram olduğu ve adeta fiilin (bir) unsurunu teşkil eden kusurluluğun ön şartını oluşturduğu görülmektedir. Bu anlayabilme kavramı ve isteyebilme gücü belirli çevrede ve belirli zamanda geçerli olan sosyal değerlere göre belirlenmektedir. ... (Z)ihni melekeleri sağ-

Klasik suç teorisi, bilimsel pozitivistizmin hukuki düşünce tarzından kaynaklanmaktadır. Hukuki meselelerin izahında, pozitif hukuk ve onun yorumu esas alınmaktadır. Hukuki meseleler, nesnel kavramlarla izah edilmeye çalışılmaktadır. Bu izahlarda felsefi değerlendirmelere, psikolojik tecrübeler ve sosyolojik gerçeklere yer verilmemektedir. “Hukuk Devleti” uğuruna(!), suçun unsurlarının izahında ifrata varan bir şekilcilik gözlemlenmektedir. Suçun bu formal objektif izahıyla ve hakimın basit, kontrol imkanı olan bu kavramlarla bağlı kılınmasıyla “hukuk güvenliği” sağlanmış olacaktır(!). Fakat, öte yandan da cezanın özel önleme fonksiyonu olduğunu kabul eden bu teori taraftarları, bir çelişkiye düşmektedirler^{25,26}.

II. Teleolojik (Neo Klasik) Suç Teorisi

19. yüzyılın sonlarına doğru kusur konusunda ileri sürülen görüşlerde pozitivistizmin önemli ölçüde etkisi olmuştur. Dolayısıyla, bu dönemdeki hukuki izahlarda pozitivistizmden kaynaklanan şekilci bir mantık hakimdir.

1880’li yılların başından itibaren “*klasik okul*”la “*modern okul*” arasındaki çatışma, cezanın *misilleme* (“*Vergeltung*”) teşkil ettiği düşüncesinin dayanağı olan irade hürriyetine ve dolayısıyla, kusur telâkkisine ilişkindi. Bu iki “okul” taraftarlarına göre; muhtevasına ilişkin fazlaca bir araştırmaya ve izaha gerek olmaksızın; kast ve taksir, kusurun iki şeklini oluşturmaktadır. “*Klasik okul*” taraftarlarına göre; irade serbestisi, kusurun tayininde esaslı faktörü oluşturmaktadır. Buna karşılık; “*modern okul*”, kusuru kastla aynı mütalâa etmektedir.

v.Liszt ve *v.Buri* tarafından formüle edilen ve bilahare *Radbruch* ve *Kohlrausch* tarafından benimsenen tanıma göre; “*kusur, kişinin icra ettiği fiille olan subjekt-*

lam veya fizyolojik bakımdan tamamiyle gelişmiş kimselerin bu yeteneğe sahip oldukları kabul olunmakta; *akıl hastaları*(nın), *küçükler*(in), *sağır-dilsizlerin* isnad yeteneğine ya hiç, ya da kısmen sahip bulunmadıkları ifade olunmaktadır.»: CGK, 24.10.1983, 6-215/358 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 606 vd.).

²⁵ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 182/183.

²⁶ Klasik suç teorisinin, “klasik okul” olarak ceza sorumluluğunun esasını açıklayan Türkçe kaynaklar için bkz. DÖNMEZER, Sulhi: *Cezai Mesuliyetin Esası*, İstanbul 1949; TOROSLU, Nevzat: *Ceza Hukukunda Okullar*, in: Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, sh. 367 vd.; TÜMERKAN, Somay: *Klasik, Pozitivist Okullarda ve Toplumsal Savunma Hareketinde Ceza Sorumluluğunun Esası*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt: XLVIII-XLIX, yıl 1982-1983, sayı 1-4, sh. 52; ARTUK, Emin: *Ceza Hukukunun Tarihi*, in: Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989, sh. ... vd.; ÜZÜLMEZ, İlhan: *Ceza Sorumluluğunun Esası ve Cezalandırmanın Amacına Dair Düşünce Hareketleri*, *Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi*, in: Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: V, yıl 2001, sayı 1-4, sh. 259 vd.

Mutlakiyetçi anlayış olarak “klasik okul”, cezanın bizatihi kendisinin amaç olduğunu kabul etmektedir (ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 12; İÇEL/DONAY, 3. bası, sh. 5). Keza, “klasik okul”, suçun karşılığında yaptırım olarak sadece cezayı öngörmektedir (TOROSLU, Kunter’e Armağan, sh. 369). Güvenlik tedbiri kavramı, “klasik okul” a yabancıdır.

tif (manevi) ilişkisinden ibarettir". Bu tanımla birlikte "psikolojik kusur" kavramı tezahür etmektedir²⁷.

20. yüzyılın başına doğru "Yeni Kantçılık" ("Neukantianismus") akımının sonucu olarak; hukuki muhakemede pozitif hukuk anlayışından yavaş yavaş sarfınazar edilip; "değer filozofisi"nin etkili olduğunu müşahede etmekteyiz. Hukuk metodolojisinin tabii bilimlerden farklılığı, hukuki muhakemede amaç unsurunun ön plana çıkmasıyla anlaşılmıştır. Bu suretle, insan davranışıyla meydana gelen netice arasında, soyut illî ilişkinin, bir değer ilişkisinin varlığı ceza hukuku biliminde de etkisini göstermeye başlamıştır²⁸.

Bu teori, ceza hukuku tarafından takip edilen amaçlara ve ceza hukukunun temelinde yatan değer yargılarına istinaden, suç kavramının izahını istihdaf etmektedir.

Bu suretle, ceza hukukunun mahiyeti, sebep-sonuç ilişkisine dayalı yalın tabii vakıalar manzumesinde değil; bu vakıaların ifade ettiği belli değer(sizlik)lerin araştırılıp ortaya konulmasında kendisini izhar edecektir.

Yeni Kant'çı Düşünceyle, klasik suç teorisinin ortaya koyduğu suçun unsurlarında bir değişiklik süreci başlamış bulunmaktadır.

Önce, klasik suç teorisine göre bizatihi herhangi bir değer ifade etmeyen hareketin, başlı başına bir değer taşıdığı müşahade edilmiştir.

Gerçi bu görüşe mensup bir kısım yazarlar, icraî hareketle ihmalî hareketi müşterek bir başlık altında incelemenin imkânsız olduğu düşüncesiyle²⁹, hareket kavramından tamamen sarfınazar edip; ilk defa kanunî tarife uygunluğun iza-hıyla suçun yapısını incelemeyi denemişlerdir³⁰.

E.Schmidt, v.Liszt'in kitabının 24. basısında onun yalın tabii anlamdaki hareket kavramını terk edip, hareketi "insanın dış sosyal çevredeki iradî davranışı" olarak tanımlamaktadır³¹: "Sosyal hareket kavramı". Bilahare Engisch³², Schröder³³

²⁷ Kusur, fail ile fiil arasındaki psikolojik bir ilişkidir: TANER, M. Tahir: *Ceza Hukuku Umumi Kısım*, 3. bası, 1953, sh. 301/302; KUNTER, Nurullah: *Suçun Kanunî Unsurları Nazariyesi*, İstanbul, 1949, sh. 64, 98, 99; TOROSLU, Nevzat: *Ceza Hukukunda Zaruret Hali*, Ankara, 1968, sh. 74; aynı yazar, *Ceza Hukuku*, sh. 96; HAKERİ, *Ceza Hukuku*, 5. bası, sh. 215.

²⁸ Bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 51, dn. 66.

²⁹ RADBRUCH: *Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem*, Berlin 1904, sh. 143.

³⁰ Örnek, RADBRUCH: *Zur Systematik der Verbrechenslehre*, in: Festgabe für Reinhard von Frank, Band I, Tübingen 1930, sh. 162.

³¹ v.LISZT, Franz/SCHMIDT, Eberhard: *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*(24), sh. 154.

³² ENGISCH, Karl: *Der finale Handlungsbegriff*, in: Probleme der Strafrechtserneuerung, Festschrift für Eduard Kohlrausch, Berlin, 1944, sh. 141 vd.

³³ SCHÖNKE/SCHRÖDER(17), Vor. vor § 1, Kn. 27a.

ve *Mezger*³⁴, hareket kavramına ilişkin izahlarında *E.Schmidt*'i izlemektedirler. Fakat, netice, yine hareketin içinde mütalâa edilmektedir. Böylece, belli bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi ön plana çıkarılırken, hareketin illî karakterine sadık kalınmıştır³⁵. Gerçi *Maihofer*, neticenin, hareket içinde değil, ilk defa kanunî tarif (tipiklik) içinde tetkik edilmesi gerektiğini savunmaktadır³⁶. Fakat, aynı zamanda, iradenin neye yönelik olduğunun araştırılmasının yine harekete dair izahla bir alâkasının olmadığını ileri sürmekle, bir çıkmaza girmiş bulunmaktadır. Bu suretle hareket, suçun yapısının izahında bir fonksiyon icra edemez duruma düşmektedir³⁷.

Yeni Kant'çı Düşünce akımının, bağlayıcı maddi değerler ölçütünden sarfınazar etmesi nedeniyle; bu değerlerin neler olduğu muğlâk kalmaktadır³⁸.

Teleolojik suç teorisine mensup yazarlar, hareketin bizzat bir değer ifade ettiğini müşahade etmişlerdir. Ancak, hareket, suçun izahında fonksiyon icra eden bir kavram olma özelliğini yitirmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, hareket kavramı yeniden ele alınıp izah edilmelidir³⁹.

Kanunî tanım (tipiklik) içerisinde manevi, sübjektif unsurların varlığının müşahade edilmesi, tipikliğin *tipik haksızlık* olarak ve kusurun ise, *normatif kusur* olarak anlaşılması karşısında; kastın suç tanımındaki yeri tamamen belirsizleşmektedir. Bu durum karşısında, kast, taksirle beraber yine bir kusurluluk şekli olarak mı telakki edilecek, yoksa suçun haksızlık unsuru içinde bir görev mi üstlenecektir? Bu sorulara henüz net bir cevap verilmiş değildir.

Aynı şekilde, taksir, sadece bir kusurluluk şekli olarak mı anlaşılmaktadır, yoksa kasdî suçlarda olduğu gibi, taksirli suçların da kendisine mahsus bir haksızlık muhtevası mı mevcuttur? Her ne kadar taksirli hareketin hukuka aykırılık muhtevasını, meydana gelen netice ile birlikte, objektif özen yükümlülüğünün ihlâlinin oluşturduğu anlaşılmış ise de⁴⁰; taksirli suçların izahına ilişkin kapsamlı bir teori henüz oluşturulamamıştır.

³⁴ MEZGER, Edmund: *Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik. Eine ergänzende Betrachtung zum Lehrbuch des Strafrechts in seiner 3. Auflage (1949)*, Berlin/München, 1950, sh. 12; aynı yazar, *Die Handlung im Strafrecht*, in: Festschrift für Theodor Rittler, Aalen, 1957, sh. 119 vd.

³⁵ Nitekim MEZGER, *Moderne Wege*, sh. 14; aynı yazar, Rittler-F., 119.

³⁶ MAIHOFFER, Werner: *Der Handlungsbegriff im Verbrechenssystem*, Tübingen, 1953, sh. 70.

³⁷ Nitekim RADBRUCH, Frank-Festgabe I, sh. 162.

³⁸ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 184. Bu farklı değer ölçütleri hakkında bkz. aynı sh. 184, dn. 30.

³⁹ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 187.

⁴⁰ ENGISCH, Karl: *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht*, 1930, sh. 278, 343 vd.

Ayrıca, işlenen fiilin bir haksızlık teşkil edip etmediği ve işlenen fiilin hukuka uygun olup olmadığı konusundaki yanılığ halinde meselenin nasıl halledileceği ayrıntılı bir izaha muhtaçtır⁴¹.

Ancak, “sosyal hareket kavramı”nın⁴² gelişimi dikkate alındığında, hareketin illilik karakterinden yavaş yavaş uzaklaşılarak, failin kişiliğine ilişkin unsurların harekete esas kimliğini kazandırdığı konusundaki kanaatin yaygınlaştığı müşahade edilmektedir.

“Sosyal hareket kavramı”nda -icraî veya ihmali olsun- insan davranışının sosyal bakımdan arzettiği önem ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle de, illi hareket kavramından⁴³ farklı olarak, sosyal hareket kavramı bir değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır: İnsan davranışının sosyal bakımdan önem arz edip etmediği araştırılırken, harekete normatif bir mahiyet kazandırılmaktadır⁴⁴.

Yeni Kant’çı Düşünce yapısının suç teorisinde sebebiyet verdiği en önemli değişiklik, suçun maddi unsurları alanında kendisini göstermektedir. Suçun kanunî tanımında *değerlendirilebilir (normatif) unsurların* da bulunduğu keşfedilmesiyle, klasik suç teorisinin benimsediği değerden yoksun ve sadece tanımlanabilir (deskriptif) unsurlardan müteşkil tipiklik anlayışı terkedilmiştir. Bu değerlendirilebilir (normatif) unsurlar, anlam muhtevalarının ilk defa hakim tarafından belirlenmesiyle uygulanabilir müşahhas bir bünyeye sahip olacaklardır⁴⁵. Şöyle ki, Türk Ceza Kanunu açısından örneğin bir hareketin “*hayasızca*” olması (m. 225); söz, yazı veya görüntünün “*müstehcen*” olması (m. 226); bir

⁴¹ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 187.

⁴² Kavram hakkında bilgi için Türkçe kaynak olarak bkz. ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 35 vd.; YÜCE, Turhan Tufan: *Ceza Hukuku Dersleri, cilt I, Giriş: Genel Bilgiler. Ceza Hukukunun Yürürlüğü. Suç Teorisi*, 1982, sh. 201.

Bu kavram eleştiriye tabi tutulmuştur: Harekete atfedilen “sosyal bakımdan önemlilik” (“Sozialerheblichkeit”) şeklindeki sıfat, harekete müşahhas bir anlam kazandırmamaktadır. Şayet özel suç tiplerinden önce ve bunlardan bağımsız olarak bir hareketin sosyal bakımdan arzettiği önem tespit edilecekse, hareket kavramının alanı aşırı ölçüde genişletilmiş olacaktır. Zira, prensip olarak, her insan davranışı sosyal bakımdan önemlidir (BLEI, Hermann, *Strafrecht I, Allgemeiner Teil*, 17. Auflage, München, 1977, sh. 4/5; MAURACH/ZIPF I, sh. 202). Buna karşılık, eğer hareketin sosyal bakımdan arzettiği önem özel suç tipleri gözönünde bulundurulmak suretiyle tayin edilecekse; o zaman suçun tipikliğe takaddüm eden bir unsuru olarak hareket kendisine atfedilen fonksiyonu icra edemez. Sosyal bakımdan arzettiği önem dikkate alınacaksa, hareketin sınırlayıcı bir fonksiyon icra etmesi mümkün olmayacaktır (MAURACH/ZIPF I, sh.202). Bu nedenledir ki, “sosyal bakımdan arzettiği önem”, insan davranışı olarak harekete ilk defa varlık kazandırmamaktadır. Bu husus, harekete bilahare ilave edilmiş bir sıfat karakterini haizdir (MAURACH/ZIPF I, sh.202; BLOY, Rene: *Finaler und sozialer Handlungsbegriff*, ZStW 90(1978), sh. 609 vd. [620 vd.]).

⁴³ İlli hareket kavramı hakkında bilgi için bkz. ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 21 vd.; YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 199.

⁴⁴ MAURACH/ZIPF I, sh. 201.

⁴⁵ MEZGER, Edmund: *Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände*, Festschrift für Ludwig Traeger, 1926 (Repr. 1979), sh. 216 vd.; HEGLER, Frank-Festgabe I, sh. 274 vd.

yazılı kağıdın “*belge*” (“*evrak*”) niteliğinde olup olmadığı, bu belgenin “*resmî*” veya “*özel belge*” niteliğinde olup olmadığı (m. 204 vd.) gibi hususlar, suçun değerlendirilebilir (normatif) unsurlarını oluşturmaktadırlar.

Bunun yanı sıra; suçun kanunî tanımı içerisinde manevî, sübjektif unsurların da bulunduğu müşahade edilmesiyle, klasik suç teorisinin yalın objektif, maddi unsurlardan müteşekkil tipiklik anlayışı da terkedilmiş bulunmaktadır⁴⁶.

Klasik suç teorisinde hukuka aykırılık, bir hukuk normunun sadece şekli anlamda ihlâli olarak telâkki edilmekteydi⁴⁷. Fakat, suçun teleolojik perspektifle incelenişi, suç olarak tavsif edilen davranışın maddi bir haksızlığı ifade ettiğini müşahade etmemizi mümkün kılmıştır⁴⁸. Bu anlayış, bilahare, fiilin hukuka aykırılığının, ya mevcuttur veya değildir şeklinde, kesin olarak tayin edilmesine karşılık, suçun ifade ettiği haksızlığın, hukuki değerlerin ihlalinin ağırlığına göre, artıp eksilebileceğinin keşfini sağlamıştır⁴⁹.

Klasik suç teorisinin aksine, tipiklik, artık haricî bir vakıanın değerden yoksun bir şekilde tanımlanması olarak anlaşılmamaktadır. Suçun kanunî tanımı içerisinde değerlendirilebilir (normatif) unsurların varlığının ve suç teşkil eden fiilin ifade ettiği maddi haksızlığın müşahade edilmesiyle birlikte, tipikliğin bizzat kendisinin bir değer ifade ettiği anlaşılmıştır. *Tipiklik* içinde “*cezaya layık bir haksızlığın kanuni tarifi*” yapılmış olmaktadır. Bu suretle, tipiklik kavramı yerine, “*tipik (kanunî tarife uygun) haksızlık*”⁵⁰ kavramının kullanılması tercih edilmiştir.

Bunun sonucu olarak, klasik anlayışta olduğu gibi, tipiklik (kanunî tarife uygunluk), hukuka aykırılık ve kusurun yanında müstakil bir unsur olarak değil, suç teşkil eden fiilin hukuka aykırılık unsurlarını belirleyen şekli bir görev üstlenmiştir. Buna göre, hukuka aykırılık ve kusur olmak üzere, suçun sadece iki unsuru mevcuttur.

Hukuka aykırılık kavramına maddi bir anlam muhtevası kazandırılmak suretiyle, kanunen belirlenenlerin dışında yeni hukuka uygunluk sebepleri ihdas edilmiştir: Başka türlü hareket etme imkânı bulunmayan bir durumda daha yüksek değerdeki bir hukuki varlığı korumak için daha az değerdekini feda edilmesi, hukuka uygun bir davranış olarak telakki edilmektedir.

Keza, teleolojik suç anlayışında, psikolojik kusur kavramından vazgeçilip, değerlendirmeye dayalı (normatif) kusur kavramı ihdas edilmiştir. Hukuk düzenince

⁴⁶ MEZGER, GS 89(1924), sh. 207; aynı yazar, Traeger-Festschrift, sh. 195 vd.; HEGLER, Frank-Festgabe I, sh. 251 vd.

⁴⁷ Bu hususta bkz. DÖNMEZER/ERMAN II, no. 681.

⁴⁸ MEZGER, Traeger-Festschrift., sh. 198 vd.; v.LISZT/SCHMIDT, Lehrbuch(26), sh.176.

⁴⁹ KERN, Eduard: *Grade der Rechtswidrigkeit*, ZStW 64 (1952), sh. 255, 276 vd. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 209, dn. 63; aynı yazar, “*Kavga Suçu*” (TCK., mad. 464) *Üzerine Düşünceler*, Yargıtay Dergisi, cilt 19, Ekim 1993, sayı 4, sh. 477 vd. (490).

⁵⁰ “tatbestandsmaessiges Unrecht”.

ihtas edilen mükellefiyetlere aykırı bir şekilde irade oluşumu faile kusur olarak atfedilmekte ve bu nedenle fail muaheze edilmektedir⁵¹. Normatif kusur anlayışına göre, meselâ kusur yeteneği olmayan bir kimseye, kasten hareket etmekle beraber, kusur isnadı kabil olmayacaktır. Zira, akıl hastası bir kimseden hukukun gereklerine uygun irade oluşturması beklenemez. Keza, zaruret halinde bulunan kişinin işlediği fiil kasdî bir fiil olmakla beraber, kendi hayatına yönelik olan tehlikeyi başka türlü bertaraf edememesi nedeniyle, yine kendisine kusur atfı kabil olmayacaktır. Taksirli suçlarda faile, neticeyi öngörmemiş olması dolayısıyla değil; bilakis, hukuk düzenince kendisine tahmil edilen özen yükümlülüğünün ifası sırasında gösterdiği dikkatsizlik nedeniyle kusur atfedilmektedir⁵².

III. Amaççı (Gaî, Final) Suç Teorisi

1930’lu yılların başından itibaren *Hans Welzel*, Ontolojik Felsefeyi esas alarak⁵³, hareket kavramına yeni bir izah getirmektedir⁵⁴. Belli bir neticeyi istihdaf eden, amaççı, gaî, ereksel, (intentional, final) hareket, “gaî hareket kavramı”, gaî (finalist) suç teorisinin esasını oluşturmakta ve suçun genel unsurlarına ilişkin bütün izahlarda bu hareketin taşıdığı özellikler gözönünde bulundurulmaktadır.

Buna göre, gaî (final) hareket, herhangi bir neticenin oluşumuna sebebiyet veren mücerret iradî faaliyet olmayıp, belli bir neticenin oluşumunu istihdaf eden, bu amaca matuf bir harekettir. Buradaki gaî faaliyet, belirlenen bu gayenin gerçekleşmesine ve bunun için elverişli vasıtaların tayinine, bir başka ifadeyle, suç işleme kararının icrasına taalluk etmektedir⁵⁵. Böylece, harekete bu vasfını kazandıran, yönlendirici iradedir, gaîliktir. Suçun yapısına ilişkin geleneksel izahlardan farklı olarak; finalist suç teorisinde, sözünü ettiğimiz bu hareket kavramına dayanılarak, suçun yapısı izah edilmeye çalışılmıştır.

Buna göre; hareket açısından zarurî olan yönlendirici irade, kasta taalluk etmektedir⁵⁶. Haksızlığa müteallik diğer manevi (sübjektif) unsurlarla⁵⁷ birlikte, kast; suç teşkil eden fiile haksızlık muhtevasını kazandıran *manevi* (sübjektif) bir *unsur* olarak, suçun kanunî tarife uygunluk (tipiklik) unsuru içinde yer almaktadır⁵⁸.

⁵¹ FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, sh. 11; GOLDSCHMIDT, Frank-Festgabe I, sh. 431 vd.

⁵² JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 186.

⁵³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 85, dn. 263. Ayrıca, sözkonusu felsefi hareketin *Welzel* üzerindeki etkileri hk. bkz. WELZEL, Hans: *Das neue Bild des Strafrechts*, 4. Auflage, 1961, “Vorwort zu 4. Auflage”.

⁵⁴ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 86 dn. 264.

⁵⁵ WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, ZStW 58(1939), sh. 503/504; aynı yazar, *Das neue Bild*, sh. 2; aynı yazar, Lehrbuch, sh. 34.

⁵⁶ “Finalität” = “Vorsatz”; gaîlik = kast.

⁵⁷ “sübjektive Unrechtselemente”.

⁵⁸ WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, 1935, sh. 83 vd.; aynı yazar, *Das neue Bild*, sh. 28; aynı yazar, Lehrbuch, sh. 60/61; aynı yazar, ZStW 58(1939), sh. 505.

Taksirli hareket de gaî hareket olarak tanımlanmaktadır. Ancak, gaîliğin müteallik olduğu husus itibarıyla her iki hareket şekli birbirinden ayrılmaktadır. Harekete mümeyyiz vasfını kazandıran gaîlik⁵⁹, yani yönlendirici irade; kasdî suçlarda sosyal bakımdan tasvip edilmeyen kanunî tarife uygun neticenin gerçekleşmesine matuf iken; taksirli suçlarda, hukuken önem arzetmeyen bir neticeye yöneliktir. Bir başka ifadeyle; taksirli suç tiplerinde, gaî hareketle istihdaf edilen neticeden ziyade, ya sosyal bakımdan tasvip edilmeyen neticenin gerçekleşmeyeceğine fail tarafından güvenilmesi (bilinçli, şuurlu taksir) ya da bu neticenin gerçekleşeceğini tasavvur edilmemesi (bilinçsiz şuursuz taksir), suçun ana noktasını teşkil etmektedir⁶⁰. Böylece, taksirli suçlar açısından belirleyici olan haksızlık unsuru, meydana gelen neticenin ifade ettiği mücerret değersizlikte değil; gerçekleştirilen hareketle “trafiğin gerekli kıldığı özen, itina gösterilmiş olsaydı” bulunulması gereken hareket arasındaki uyumsuzlukta, çelişkide tezahür edecektir⁶¹. Kısacası, bu unsur, kaynağını *hareketin ifade ettiği değersizlik*ten almaktadır.

Final hareket kavramının esas alındığı suç teorisinde, suçun yapısal unsurlarında değişiklik öngörülmektedir:

Suçun kanunî tarifi (tipiklik) içinde yer alan manevi (sübjektif) bir unsur olarak kast, suç teşkil eden fiile haksızlık muhtevasını kazandırırken, “*tabîi anlamda kast*”⁶² şeklinde anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle, işlenen fiilin bir haksızlık teşkil edip etmediği, esasen suç olan bir fiilin işleniş sırasında bir hukuka uygunluk sebebinin mevcut olup olmadığı konusundaki bilinç, şuur, kasta dahil edilmeyip, kusurluluk içinde mütalaa edilmektedir.

Buna bağlı olarak; o ana kadar geçerli olan “fiilî hata - hukukî hata” ayırımından vazgeçilmektedir⁶³. Suçun kanunî tanımındaki maddi (objektif) unsurlarda yanlışlığı ifade eden ve kastı bertaraf eden yanlışlığa, *unsur yanlışlığı*⁶⁴ denmektedir. Suçun kanunî tanımındaki maddi unsurlardan birisine müteallik yanlışlığı halinde kastın varlığından bahsedilemeyecektir. Buna karşılık, işlenen fiilin hukuka aykırılık teşkil ettiği konusundaki bilinçten yoksunluk halinde *yasaklılık yanlışlığı*⁶⁵ söz konusudur. Yasaklılık yanlışlığının varlığına rağmen, kanunî tarifte yer alan unsurlara müteallik kast varlığını yine de devam ettirir. Yasaklılık yanlışlığının varlığı halinde de, bu yanlışlığın kaçınılabılır olup olmadığına göre

⁵⁹ “Finalität”.

⁶⁰ WELZEL, Lehrbuch, sh. 129/130.

⁶¹ WELZEL, Das neue Bild, sh. 31.

⁶² “natürlicher Vorsatz”.

⁶³ WELZEL, Aktuelle Strafrechtsprobleme im Rahmen der finalen Handlungslehre, 1953, sh. 10 vd.

⁶⁴ “Tatbestandsirrtum”.

⁶⁵ “Verbotsirrtum”.

bir ayırım yapılmaktadır⁶⁶. Bu yanılmanın kaçınılmaz olduğu hallerde kusur isnadından sarfınazar edilecektir. Yanılmanın kaçınılabılır olduğu hallerde, derecesi azalmış olsa bile, kusur varlığını devam ettirmektedir. Bu ayırım çerçevesinde, bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında yanılığa düşülmesi hali de yasaklılık yanılığı içinde mütalaa edilmektedir: “*Kat’i kusur teorisi*”⁶⁷.

Kusur, yalın bir değer yargısı olarak anlaşılmaktadır.

Gai suç teorisine mensup yazarlarca, ihmalî suçlar, kasdî ve taksirli suçların yanısıra üçüncü bir suç grubu olarak anlaşılmaktadır.

Welzel, gai hareket kavramını⁶⁸ esas alarak, o zamana kadarki mevcut suç teorisinde izah güçlüğüyle karşılaşılacak bir çok muğlak hususa tatmin edici izahlar getirmektedir. Ancak, bu izahlar için mutlaka gai (final) hareket kavramının esas alınmasına gerek yoktur. Suç teorisi açısından yeni bir devir açan *Welzel*’in bu görüşleri, suçun izahına ilişkin halen mer’î olan metodolojik esaslardan hareket etmek suretiyle de varılabilecek hususlardır. Aradaki fark şu şekilde tezahür etmektedir: *Welzel*’in esas aldığı düşüncenin ontolojik düşünce olmasına karşılık; gelenekçi metodolojiye sadık kalan yazarlar, değerlendirmeci (normatif) bir yaklaşımla suç teorisine ilişkin münferit izahları yapmaktadırlar.

Gai hareket kavramını esas alan bu suç teorisine birçok noktada eleştiri yöneltlmıştır⁶⁹. Ancak, bu eleştirilerden en önemlisi, taksirli hareket ile gailik arasındaki ilişkiye yönelik olanıdır. Gailik, yönlendirici irade ile tasvip edilmeyen netice arasındaki psikolojik bağ olduğuna göre; bu bağın taksirli hareketlerde mevcut olmadığı muhakkaktır. Bu itibarla, *Welzel*, daha başta gailiği, kasdî hareketler için “aktüel gailik” olarak tavsif ederken, taksirli hareketler açısından “potansiyel gailik”ten söz etmiştir⁷⁰. Ancak, bu anlayış büyük bir eleştiriye maruz kalmıştır⁷¹.

Aynı şekilde, *Welzel*, kanunî tarife uygun ve tasvip edilmeyen neticenin gerçekleşmesinden “potansiyel olarak sarfınazar edilebileceği” hususuna, daha hareket kavramını incelerken yer vermek suretiyle; hareketin gailik özelliğinin ontolojik bir vakıa olduğu konusunda baştan beri ileri sürdüğü fikirle çelişkiye düşmektedir⁷². Taksirli hareketin yapısını incelerken bir değerlendirmeye müracaat edil-

⁶⁶ WELZEL, Lehrbuch(11), sh. 164 vd.

⁶⁷ “strenge Schuldtheorie”: WELZEL, Das neue Bild, sh. 70 vd.

⁶⁸ Kavram hakkında bilgi için Türkçe kaynak olarak bkz. ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 29 vd.; YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 200.

⁶⁹ Bu eleştiriler için bkz. MAURACH(4), § 16 II C 2 a.; MAURACH/ZIPF I, sh. 197/198.

⁷⁰ WELZEL, Lehrbuch(11), sh. 200; aynı mealde KAUFMANN, Armin: *Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte*, 1959, sh. 83.

⁷¹ MEZGER, Moderne Wege, sh. 18; MAIHOFER, Handlungsbegriff, sh. 39.

⁷² Aynı şekilde NIESE, Finalität, sh. 43.

mehtir. Fakat, tasvip edilmeyen neticenin oluşumuna sebebiyet veren bu hareketin kaçınılabilir olup olmadığı, ilk defa kusurluluk bahsinde tetkik edilmesi gerekirken⁷³; bu anlayışa göre, daha harekete ilişkin izahta ele alınmaktadır. Bu anlayış, taksirli suçların haksızlık muhtevasıyla kusur muhtevasının birbirinden ayırımını imkansız kılmakta ve ancak kusur yeteneği olan şahsın taksirli suçun faili olabileceğini intaç etmektedir⁷⁴.

Bu eleştiriler çerçevesinde bilahare *Welzel*, taksirli hareketin de gaî hareket olduğunu, bu gaîliğin ontolojik mahiyet taşıdığını; ancak, gaîlikle istihdaf edilen neticenin tipiklik dışında bir netice olduğunu ileri sürmekle, eski görüşlerini kısmen düzeltmiştir⁷⁵. Ancak, buna rağmen, taksirli suçlara müteallik bu anlayışa yöneltilen esaslı eleştiri halen geçerliliğini idame ettirmektedir: Özellikle bilinçsiz taksirde gaîlik, cezaî sorumluluğun esasını oluşturan neticeye yönelik olmamaktadır⁷⁶. Taksirli suçlarda cezalandırılabilirlik, belirli amaca matuf olarak hareketi yönlendirmemekten kaynaklanmaktadır. Kişilere genel bir yükümlülük olarak atfedilen ve fail açısından da mümkün olan gaî yönlendirmenin müşahhas olayda mevcut olmaması halinde taksirden bahsedilebilir⁷⁷.

Hareketin bizzat icra ediliş tarzının bir haksızlık ifade ettiği hususunun tespiti tamamen gaî suç teorisinin ürünüdür. Gerek kasdî gerek taksirli suçlarda hareketin bizzat icra ediliş tarzı bir haksızlık ifade etmektedir. Buna göre; taksirli suçlarda, hareketin objektif özen yükümlülüğüne aykırı olması, bu harekete haksızlık karakterini kazandırmaktadır⁷⁸.

IV. Sentezci Yaklaşım

Günümüzde teleolojik suç teorisinin etkisindeki ceza hukukçuları tarafından da, kastın suçun manevî unsuru olarak kabul edilmesi, gaî suç teorisinin bir sonucudur.

Ancak, gaî suç teorisinin etkisindeki ceza hukukçularından *Stratenwerth* ve *Jakobs*, taksirli suçlarda bizzat failin özen yükümlülüğüne, bu yükümlülüğün gereklerine uygun olarak davranabilme yeteneğini suçun kanunî tarifine ithal etmektedirler⁷⁹. Bu suretle, taksirli suçlarda haksızlık unsuruyla kusur unsurunun ayırımı ortadan kaldırılmış olmaktadır.

⁷³ Nitekim NIESE, Finalität, sh. 44.

⁷⁴ MAURACH/ZIPF I, sh. 198.

⁷⁵ WELZEL, Hans: *Die deutsche strafrechtliche Dogmatik der letzten 100 Jahre und die finale Handlungslehre*, in: JuS 66, sh. 424; aynı şekilde MAURACH, Lehrbuch(4), § 16 II C 2 b.

⁷⁶ MAURACH/ZIPF I, 193; LENCKNER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. § 13, kn. 33.

⁷⁷ MAURACH/ZIPF I, sh. 199.

⁷⁸ Gaî hareket teorisinin en büyük kazancı, iradenin muhtevasının hareketten ayrık olarak mütalâa edilemeyeceği hususudur (HARDWIG, Die Zurechnung, sh. 86).

⁷⁹ STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn., 1097 vd.; JAKOBS, *Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt*, 1972, sh. 48 vd, 55 vd; aynı yazar, Lehrbuch(1), sh. 261 vd.

Teleolojik suç teorisinin etkisindeki günümüz ceza hukukçuları, suçun izahında, sebebiyet verilen neticeyi değil, insan davranışının sosyal bakımdan arzettiği önem nedeniyle, icra edilen hareketi esas almaktadırlar. Ancak, suçun izahında, hareketin icra ediliş tarzının ifade ettiği haksızlığın yanı sıra, meydana gelen neticenin de ifade ettiği haksızlığı dikkate almaktadırlar. Bu suretle, gaî (final) suç teorisinin, neticenin ifade ettiği haksızlığı göz ardı ederek, suçun izahında sadece icra edilen hareketin ifade ettiği haksızlığı esas almasıyla ortaya çıkan tehlike⁸⁰ bertaraf edilmiş olmaktadır⁸¹.

Teleolojik Suç Teorisinin etkisiyle ortaya çıkan sosyal hareket kavramı, *Jescheck* tarafından gaî (final) ve sosyal unsurlardan oluşan bir kavram olarak yeniden formüle edilmeye çalışılmıştır. Bu suretle, kast, suçun haksızlık unsuru içinde (de) yer alarak, fonksiyon icra etmektedir⁸². *Jescheck*'e göre, davranış “insanın kendi (irade) serbestisine müterafık olarak sahip olduğu tepki imkanını gerçekleştirmek suretiyle, müşahede edilen veya en azından müşahede edilebilen halin icabına verdiği cevaptır”⁸³. Söz konusu bu davranış, ancak bunun insanın kendi çevresiyle olan ilişkisine müteallik olması ve çevresinin de bundan dolayı etkilenmesi halinde, sosyal bakımdan önem arzedecektir⁸⁴. Bunun için, söz konusu davranış dış dünyada etkili olmak zorundadır.

İcraî insan davranışının ontolojik karakteri, belli bir gayeye matuf oluşudur⁸⁵.

Ancak, meseleye ontolojik bir perspektifle bakıldığında icraî davranışla ihmalî davranış arasında bir müştereklik tespiti mümkün değildir. Her iki davranış biçiminin müşterek bir hareket kavramı altında toplanması ancak normatif alanda; başka bir ifade ile, bir değerlendirmeye kabildir. Söz konusu müştereklik, insan davranışının çevre ile olan ilişkisinde aranacaktır. Buna göre, hareket, sosyal bakımdan önem arzeden bir insan davranışdır⁸⁶.

Aynı şekilde *Wessels*, hareket kavramını, “insan iradesince hükmolunan veya hükmolunabilen ve sosyal bakımdan önem arzeden davranış” olarak tanımlamak-

⁸⁰ *Welzel*'in öğrencilerinden *Arm.Kaufmann* ve *Zielinski*, suç teskil eden fiille tezahür eden şahsi haksızlık (das personale Unrecht) için hareketin ifade ettiği değersizliğin (der Handlungsunwert) yeterli olduğu kanaattindeler. Neticenin gerçekleşmesi ise, bu yazarlara göre, bir haksızlık ifade etmeyip, sadece objektif cezalandırılabilme karakterini haizdir (KAUFMANN, Armin: *Zum Stande der Lehre vom personalen Unrecht*, in: *Festschrift für Hans Welzel*, 1974, sh. 393 vd. [410/411]; ZIELINSKI: *Handlungs - und Erfolgswert im Unrechtsbegriff*, 1972, sh. 143, 172 vd., 208 vd.)

⁸¹ MAURACH/ZIPF I, sh. 202.

⁸² JESCHECK, Hans Heinrich: *Der strafrechtliche Handlungsbegriff in dogmengeschichtlicher Entwicklung*, in: *Festschrift für Eberhard Schmidt*, Göttingen, 1961, sh. 139 vd. (153/154).

⁸³ JESCHECK, Lb.(4), sh. 201.

⁸⁴ JESCHECK, Lb.(4), sh. 201.

⁸⁵ (Gailik = Finalität): JESCHECK, Lb.(4), sh. 199, 201.

⁸⁶ JESCHECK, Lb.(4), sh. 200.

tadır⁸⁷. Bu tanımla hareketin, hem insan kişiliğiyle mürtabit bir yönü, hem de ontolojik bir vakıa oluşu ortaya çıkarılmaktadır. *Wessels*, bir vakıa olarak hareketin sosyal anlam muhtevasının tespitinin, bu insan davranışının objektif unsurlarının yanı sıra, failin istihdaf ettiği amacın, gayenin veya normatif bir değerlendirmeye müsteniden hukuk düzeninin kişiden nasıl davranması gerektiği konusundaki beklentisinin de dikkate alınması suretiyle mümkün olabileceği kanaatindedir⁸⁸.

Gai suç teorisiyle klasik suç teorisi arasında bir sentez oluşturmayı hedefleyen *Schmidhaeuser*, suçun unsurlarını “teleolojik bir sistematik”e tabi tutmaktadır. Buna göre, ceza ile cezayı gerektiren fiil arasında maddi bir bağlantı mevcuttur⁸⁹. Cezanın münhasır amacı, genel önlemedir⁹⁰. Yazar, kastı iki kısma ayırmaktadır. Kastın bilme unsuru, işlenen fiilin bir haksızlık, hukuka aykırılık teşkil ettiği konusundaki bilinçle beraber, kusura ithal edilmektedir. Buna karşılık, “maksat”⁹¹ olarak telakki edilen irade unsuru ise, suçun haksızlık unsuruna dahil edilmektedir⁹².

Roxin, suçun unsurları belirlenirken, bunların suç siyasetiyle güdülen amaçlarla uyumunun sağlanması gerektiği fikrindedir⁹³. *Roxin*’e göre kusur, suç siyaseti itibarıyla ceza ile güdülen amaçlarla belirlenecektir⁹⁴. Özellikle kusurluluğu ortadan kaldıran sebepler, sadece cebir veya tehdit gibi hukukun gereklerine göre hareketin beklenemediği durumlara inhisar etmeyip, genel önleme mülahazalarıyla cezaya müracaatın gereksiz olduğu hallere de şamildir⁹⁵. Böylece, *Roxin*, kusurlukla cezanın genel önleme etkisi arasında bir ilişki kurmakta ve kusurluluğu bununla tamamlamaktadır: “Fonksiyonel kusur kavramı”.

Keza, *Jakobs*’a göre, suç teorisinde kusur kavramından tamamen vazgeçilmekte ve bunun yerine cezanın genel önleme düşüncesi ikame edilmektedir^{96, 97}.

⁸⁷ WESSELS, Johannes: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 19. Auflage, 1989, sh. 24.

⁸⁸ WESSELS, *Allgemeiner Teil* (19), sh. 24.

⁸⁹ SCHMIDHÄUSER, Eberhard: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch*, 2. Auflage, 1975, sh. 140.

⁹⁰ SCHMIDHAEUSER, *Lehrbuch*, sh. 52 vd.

⁹¹ “Absicht”.

⁹² SCHMIDHAEUSER, *Lehrbuch*, sh. 178 vd.

⁹³ ROXIN, Claus: *Kriminalpolitik und Strafrechtssystem*, 2. Auflage, 1973, sh. 10.

⁹⁴ ROXIN, *Kriminalpolitik*, sh. 33.

⁹⁵ JESCHECK, *Lehrbuch*(4), sh. 194, dn. 90.

⁹⁶ JAKOBS, Günther: *Schuld und Prävention*, 1976, sh. 33 vd.; *Lehrbuch*, 392 vd.; STRENG, Franz: *Schuld, Vergeltung, Generalprävention*, ZStW 92(1980), sh. 637 vd.; ACHENBACH, Hans: *Individuelle Zurechnung, Verantwortlichkeit, Schuld*, in: Grundfragen des modernen Strafrechtssystems (Hrsg. Bernd Schünemann), 1984, sh. 135 vd., 150.

Bu görüşe eleştiri için bkz. JESCHECK, *Lehrbuch*(4), sh. 194.

⁹⁷ *Jakobs*’un bu görüşü, haklı olarak, eleştirilmiştir: Kusur, genel önlemenin neticesi değil; genel önlemeyi sağlayacak bir faktördür. Genel önleme mülahazası, kusuru ne sınırlandırabilir ne

§13. Hukuki Değer İhlâli ve Haksızlık Teşkil Eden Bir Fiil Olarak Suç

Kişi, kendisinin maddi ve manevi gelişimini sağlaması, kendisini maddi ve manevi bakımdan olgunlaştırması hususunda *etik bir yükümlülük*le karşı karşıyadır. İnsan şahsiyetinin bu tekâmülü ancak toplum halinde yaşamakla mümkündür. Toplumun bu örgütlenmiş şekli olan devletin amacı, insana şahsiyetini tekâmül imkânlarını sağlamak ve insanı mutlu kılmaktır. Bu realite, Anayasamızın 5. maddesinde olduğu gibi, bütün günümüz anayasalarında açıkça ifade edilmiştir. Ancak, insanın mutluluğu için, kişiliğinin gelişimi için toplumun devlet olarak örgütlenmesi yeterli değildir. Bu devletin hukukla bağlı bir devlet, bir Hukuk Devleti olması gerekir. Bir Hukuk Devleti olarak örgütlenmiş toplum, bir hukuk toplumdur⁹⁸.

Suç, bu toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin açık ve bilinçli bir ihlâli veya en azından bu değerleri korumaya matuf kurallara özensizlik niteliği taşıyan insan davranışlarıdır. Bu yönü itibarıyla, *suç, bir haksızlıktır*; bir başka ifadeyle, hukuka aykırılık arzeden muayyen bir fiildir⁹⁹. Her hukuk kuralının temelinde bir *değer* yatmaktadır. Bu değerlerin somut bir ifade biçimi olan davranış normlarının¹⁰⁰ ilk icra ettiği fonksiyon; icraî olsun, ihmalî olsun, insanın belli fiillerinin ahlâken ve hukuken tasvip edilemez olduğu hususunda bir yargıyı ifade etmeleridir. Yani, bu normlar, belli davranış biçimleri hakkında bir *değersizlik yargısının* (veya *menfi, olumsuz*

de ortadan kaldırabilir (BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 18, kn. 22). Kusur, cezanın vazgeçilmez şartını oluşturmaktadır (BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 3, kn. 58). Kusurun aynı zamanda derecelendirilmesi de sözkonusudur. Böylece, kusur oranında cezanın sınırlandırılması mümkün olmaktadır (BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 3, kn. 59, 60). Ancak, genel veya özel önleme mülahazasıyla kusurun gerektirdiği cezadan daha az bir cezaya hükmedilebilir.

⁹⁸ “Rechtsgemeinschaft”.

⁹⁹ *Dönmezer/Erman*, suç, “sorumlu bir kimse tarafından müsbet veya menfi bir hareketle meydana getirilen, ceza tehdidini taşıyan bir kanunda yazılmış târife uygun ve hukuka aykırı olan bir fiil” olarak tanımlamaktadırlar (DÖNMEZER/ERMAN I, no. 449; aynı mealde tanım için bkz. ALACAKAPTAN, sh. 10). Keza, Yargıtay’ın tanımına göre suç, “isnad yeteneğine sahip bir kişinin kusurlu iradesinin yarattığı icraî ve ihmalî bir hareketin meydana getirdiği, kanunda yazılı tipe uygun, hukuka aykırı, müeyyide olarak bir cezanın uygulanmasını gerektiren bir fiildir”: CGK., 27.1.1984, 6-360/32 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1985 vd. [1087]).

Bu tanım, isabetli değildir. Şöyle ki; suç teşkil eden fiilin ancak “isnad yeteneği”ni haiz bir kişi tarafından işlenebileceği ve ayrıca, işlenen fiil dolayısıyla kişinin kusurlu olması gerektiği kabul edilmektedir. Halbuki, aşağıda izah edileceği vechile, kusur veya kusurlu olmak, işlenen fiilin bir vasfı değildir. Nitelik itibarıyla haksızlık teşkil eden bir fiilin işlenmesi halinde bu nedenle fail kusurlu addedilebilir.

Selçuk, suç “hukuka aykırı, kusurlu ve yasal tipe uygun insan eylemi” olarak tanımlamaktadır: SELÇUK, Sami: CGK’nın 27.1.1984 tarih ve 6-360/32 sayılı kararına muhalefet şerhi (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1090). Suç teşkil eden fiile “kusurlu” olmak şeklinde izafe edilen vasfı açısından yukarıda mezkûr eleştiri, bu tanım için de geçerlidir.

¹⁰⁰ Kavram hakkında bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Davranış Normları Teorisi, Selçuk ÜHFD V(1996), sh. 447; aynı yazar, Suça İştirak, sh. 128 vd.

anlamda bir değer yargısının)¹⁰¹ oluşumunu sağlamaktadırlar. Bu normlar, kişilerin belli davranışlarının muhteva itibarıyla doğru olmadıklarının, bir *haksızlık*¹⁰² teşkil ettiğinin tespitini sağlarlar¹⁰³. Dolayısıyla, davranış normları, toplumda değer telâkkilerinin oluşumunu sağlamaktadırlar. Bir davranışın bu normlardan birini ihlâl etmesi, bu davranışa haksızlık muhtevasını kazandıracaktır. Bir fiilin kanunla suç (veya, genel bir ifadeyle, haksızlık) olarak tarifine takaddüm eden¹⁰⁴ söz konusu normlar sayesinde bu fiilin değerlendirilmesini yapmak kabil olacaktır: *Davranış normunun değerlendirme fonksiyonu*^{105, 106}.

Davranış normlarıyla koruma altına alınan hukuki değer, bir şahıs veya eşyanın ilişkin olduğu bir husustur. Bu hukuki değerlerin nesnel bir yönü yoktur. Belli bir şahıstan soyut bir nitelik arz eden bu değerler, manevi, metafizik bir içeriğe sahiptirler¹⁰⁷. Somut bir varlığı olmayan bu değerler doğrudan doğruya zarara veya tehlikeye uğramazlar. Bu değerlere tecavüzün anlamı, kişinin işlediği fiille bu ideal değerleri tanımadığını, onun geçerliliğine karşı çıktığını göstermesidir^{108, 109, 110}.

¹⁰¹ Unwerturteil.

¹⁰² Unrecht, (gerçeği, hakkı örtme anlamında) zulm.

¹⁰³ UCHIYAMA, Minoru: *Das Wertwidrige in der Ethik Max Schelers*, 1966, 63 vd.

¹⁰⁴ Bu mülahazayladır ki, hukuki değer kavramı, “kanun üstü” kavram olarak telakki edilmekte ve “kanun koyucunun sınırlanması aracı olarak kabul” edilmektedir (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 431, 609).

¹⁰⁵ Bewertungsfunktion der Norm: KAUFMANN, Armin: *Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, Normlogik und moderne Strafrechtsdogmatik*, 1954 (erweiterter Nachdruck der 1. Auflage: 1988), sh. 67; ÖZGENÇ, İzzet: *Kusur Yargısı ve Yaş Küçüklüğü*, in: *Facultatis Decima Anniversaria* (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye Ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu), 1993, sh. 251. Ayrıca bkz. ÇOBANOĞLU, Rahmi: *Hukukta Gaye Problemi*, 1964, sh. 4, 6; HAFİZOĞULLARI, Zeki: *Ceza Normu, Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni*, 1987, sh. 25, 141 vd.; ARAL, Vecdi: *Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine*, 6. bası, 1991, sh. 57.

¹⁰⁶ Davranış Normlarının değerlendirme fonksiyonu dolayısıyla, değerlendirmeyi gerekli kılan hukuki kavramlara "normatif" kavramlar denmekte, veya kavramın "normatif" özelliğinden bahsedilmektedir (ÇOBANOĞLU, sh. 6-8).

¹⁰⁷ Hukuki değer kavramı, “manevi, düşünsel anlamda” ele alınmaktadır (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 432).

¹⁰⁸ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 127, dn. 1, sh.141, dn. 45; SÖZÜER, Adem: Suça Teşebbüs, 1994, sh. 148/149; KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler (6), sh. 110.

¹⁰⁹ 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı *Kabahatler Kanununun Genel Gerekçesi* bu bakımdan açıklayıcıdır:

“Haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili olmaktadır. Ancak, bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, bunun esasen haksızlık ifade etmesi gerektiği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Esas itibarıyla haksızlık ifade etmeyen, hukuka aykırı olmayan bir fiil hiçbir surette suç veya kabahat olarak tanımlanamaz.

Haksızlıklar arasında bu yönde bir tasnif yapılması durumunda; bu tasnifte, hukuka aykırı olan fiilin ifade ettiği haksızlık içeriği esas alınmalıdır.

Bu bakımdan, esasen hukuka aykırı olan ve haksızlık ifade eden fiiller arasında suç veya kabahat olarak bir ayırım yapılması, bir nitelik farkı oluşturmamaktadır. Söz konusu tasnif, haksızlıklar arasındaki nicelik farkına dayanmaktadır. Bu tasnif, haksızlıklar arasında sadece bir işlem farklılığı doğurmaktadır.

Hukuki değerler, hukuk toplumundaki sosyal düzenin devamı için geçerliliği zorunlu olan **ideal, manevi değerler**dir. Bu değerler, sosyal düzen açısından korunması gereken **soyut değerler**dirler¹¹¹.

Hukuki değerlerin kaynağı, *davranış normları*dır¹¹². Bu değerleri korumaya yönelik davranış normlarından kaynaklanan yükümlülükler aykırı davranışlar, *hukuka aykırılık* teşkil etmektedirler. Bu itibarla; hukuki değer kavramıyla yükümlülük kavramı arasında sıkı bir ilişki mevcuttur; ancak, aynı şeyler değildirler.

Hukuki değer, bir suça ilişkin kanunî tanımın yorumunda başvurulacak en önemli araçtır¹¹³.

Örneğin, suçlar kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Eğer kanunda açıkça belirtilmişse, taksirle işlenen fiil de istisna olarak suç oluşturabilir. Buna karşılık, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahat türünden haksızlıklar kural olarak hem kasten hem de taksirle işlenebilirler. Ancak, sadece kasten veya taksirle işlenebilen fiilin kabahat oluşturabileceği konusunda kanunda hüküm bulunabilir.

Keza, suça teşebbüs cezalandırılabilir iken, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahate teşebbüs kural olarak cezalandırılmamaktadır. Suça iştirakte suç ortakları arasında fail ve şerik (azmettiren veya yardım eden) ayırımı yapılmaktadır. Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahate iştirakte ise, tek tip fail sistemi kabul edilmiştir.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840).

Söz konusu Kanunun “Tanım” başlıklı 2’nci maddesine göre; “*Kabahat* deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.”

Bu maddenin gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Madde metninde, genel olarak kabahate ilişkin bir tanım yapılmıştır. Bu tanımlamada, suç gibi kabahatin de bir haksızlık oluşturduğu vurgulanmıştır. Esas itibarıyla haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili olmaktadır. Haksızlıklar arasında bu yönde yapılan tasnifte, hukuka aykırı olan fiilin ifade ettiği haksızlık içeriği esas alınmaktadır.

Esasen hukuka aykırı olan ve haksızlık ifade eden fiiller arasında suç veya kabahat olarak bir ayırım yapılması, bir nitelik farkı oluşturmamaktadır. Söz konusu tasnif, haksızlıklar arasındaki nicelik farkına dayanmaktadır.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840).

¹¹⁰ Demirtaş, Alman hukukunda “Rechtsgut” kavramı ile ilgili olarak yapılan açıklamaların etkisinde kalarak, hukuki değerlerin bir konusunun olduğu ve zarar veya tehlikeye maruz bırakılabileceği kabul etmektedir (DEMİRTAŞ, Tehlike Suçları, sh. 39, 41, 42, 71, 87, 105, 164, 167).

Oysa hukuki değerler saldırıya maruz bırakılabilir ve ihlal edilebilir; ancak zarar veya tehlikeye maruz bırakılan hukuki değer değil, suçun konusudur. Alman doktrinindeki yazarların görüşleri arasında okuyucuyu bir gezintiye çıkaran yazar, bir teorik konsept oluşturmamayan açıklamalarıyla, hukuki değer ile suçun konusu kavramlarını birbirine karıştırmıştır (DEMİRTAŞ, Tehlike Suçları, sh. 106, 122 [dn. 390], 129, 133, 156, 161).

¹¹¹ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 149, 474. Hukuki değerlerin soyut olması dolayısıyla, bunların sahibinden veya taşıyıcısından söz etmenin (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 480 vd.) doğru olmadığını düşünmekteyiz. Ancak bu düşüncemizden hukuki değerlerin insanla ilişkisinin olmadığı sonucu çıkarılmamalıdır.

¹¹² ÖZGENÇ, İzzet: *Davranış Normları Teorisi [Haksızlık ve Müeyyide İlişkisi]*, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, cilt V, yıl 1996, sayı 1-2, sh. 443 vd.; aynı yazar, Suça İştirak, sh. 128 vd.

¹¹³ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 502, 509, 609, 610, 846 vd.

Suç teşkil eden her fiil, aynı zamanda bir **hukuki değer**in **ihlâli** niteliği arzettiğidir^{114, 115}. Bu nedenle, bir hukuki değerle ilişkilendirilemeyen bir suçtan ve daha genel bir ifadeyle, haksızlıktan bahsedilemez¹¹⁶. Suç oluşturan fiilin işlenmesiyle, hukuki değer veya değerler ihlâl edilmektedir. Buna karşılık, aşağıda da izah edileceği üzere, suçun konusuyla bağlantılı olarak zarar veya tehlike kavramları kullanılmaktadır¹¹⁷.

Bir fiilin kanunda suç olarak tanımlanmasıyla bir veya birden çok hukuki değer koruma altına alınmış olabilir. Meselâ hırsızlık, kişinin malvarlığı hakkını korumaya yönelik olarak öngörülmüş bir suçtur. Buna karşılık; yağma suçu ise, kişinin hem vücut dokunulmazlığını, hem irade hürriyetini, hem de malvarlığı hakkını ihlâl eden bir suçtur. Keza, dolandırıcılık suçu ile, hem kişinin karar verme hürriyeti, hem de malvarlığının dokunulmazlığı ihlâl edilmektedir¹¹⁸.

¹¹⁴ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 147.

¹¹⁵ Suçun işlenmesi suretiyle ihlâl edilen *hukuki değer*dir. Bu itibarla, “suç tipinin ihlâli” ya da “suç tipindeki unsurların ihlâli” gibi ifadeler (ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 93), doğru değildir.

¹¹⁶ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 614, 789 vd.

¹¹⁷ Buna karşılık, *Ünver*, suçun işlenmesiyle hukuki değer “zarara uğraması”ndan veya “tehlikeye sokulması”ndan söz etmektedir. (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 427, 439, 464). Yazar, çalışmasının çeşitli yerlerinde ise hukuki değerle bağlantılı olarak *ihlal* kavamını kullanmaktadır (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 428, 439, 873 vd.). Yazar, “zarar veya tehlike yaratmak anlamında ihlal”den söz ederek (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 530), bu kavramları birbirine karıştırmıştır.

Keza, *Katoğlu*, hukuki değer kavramıyla bağlantılı olarak *ihlal* ibaresini kullanmakla birlikte, çalışmasının bir yerinde “*fiilin hukuki varlık ve menfaatleri zarar vermesi ya da bunları zarar tehlikesine maruz bırakması*”ndan söz etmektedir (KATOĞLU, Tuğrul: *Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık*, Ankara 2003, sh. 79. Aynı şekilde kavram karışıklığının söz konusu olduğu bir çalışma için bkz. MERAKLI, Serkan: *Ceza Hukukunda Kusur*, Ankara, Ekim 2017, sh. 39, 41, 46).

¹¹⁸ *Ünver*, hukuki değerlerin zaman ve yere göre değişken olduğunu kabul etmektedir (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 490 vd.). Yazara göre hukuki değerler, “*gerek içerik gerek şekli açıdan değişirler*.” Toplum hayatındaki gelişmeler, “*bir çok alanda (teknik, tıp vs.) yeni hukuksal değerleri meydana getirdikleri gibi, daha önceden varolan bazıların da hukuksal değer statüsünden çıkmasına ... neden olurlar*.” (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 491). Yazara göre, hukuki değerlerin “*bu değişkenlik özelliği dolayısıyla bazı yeni eylemler suç haline getirildiği gibi, önceden suç olan bazı eylemler de suç olmaktan çıkarılırlar*.” (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 494).

Öncelikle belirtmek gerekir ki, **hukuki değerlerle bağlantılı olarak “değişkenlik özelliği”nden söz edilmesi doğru olmamıştır**. Bu itibarla, birtakım hukuki değerlerin, daha önce mevcut olmadıkları ve bilahare ortaya çıktıkları söylenemez.

Hukuki değerler, insanlıkla ilişkili olmaları dolayısıyla, insanlık var olduğu sürece geçerliliklerini devam ettirirler. Ancak, bu değerlerin varlığı ile toplum bilincinde gündeme gelmesi aynı şey değildir. Örneğin, önceleri salt *yaşama (hayat) hakkından* söz edilmekteydi. Ancak, önemli olanın insanın herhangi bir şekilde yaşamasının olmadığına anlaşılmaya bağlı olarak gelişen hukuk bilinci ile insanın örneğin *sağlıklı yaşama hakkından* veya *ekolojik dengesi bozulmamış bir çevrede yaşama hakkından* söz edilmeye başlanmıştır.

Hukuki değerler kendi aralarında bir derecelendirmeye tabi tutulurlar¹¹⁹. Bu nedenle, hukuki değerler, suçların tasnifinde başvurulacak yegane ölçüt olma özelliğini taşımaktadır¹²⁰. Meselâ, kişinin hayatına ve vücut dokunulmazlığına (mahremiyetine) karşı işlenen suçlar, kişinin şerefine, haysiyetine karşı işlenen suçlar, kişinin malvarlığına karşı işlenen suçlar, kendi aralarında düzenlemeye tabi tutulmuşlardır.

Hukuki değerlerin aralarındaki bu derece farklılığı zorunluluk halinin uygulanması bakımından büyük bir önem taşımaktadır¹²¹. Aşağıda açıklanacağı üzere, zorunluluk halinde, bir hukuki değerle ilişkin olduğu konu (örneğin bir kişinin hayatı) tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu konunun korunması uğruna daha az dere-

Bunlardan *sağlıklı yaşama hakkı*, insanlara devlet eliyle sağlık hizmetlerinin sunulmasının ya da etkin ve işlevsel sosyal güvenlik politikalarının izlenmesinin temel itici gücünü oluşturmaktadır. Keza, söz konusu hak, insan vücuduna teşhis ve tedavi amacına yönelik tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğunun izahında ana hareket noktasını oluşturmaktadır.

Doğal kaynakları hoyratça kullanılmasının sonucu olarak bozulmaya yüz tutan ve hatta yer yer bozulan ekolojik dengenin korunması ihtiyacı karşısında, insanın *ekolojik dengesi bozulmamış bir çevrede yaşama hakkı*ndan söz edilmeye başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, çevrenin kirlenmesi fiillerinin ceza kanunlarında suç olarak tanımlanması yoluna gidilmiştir. Nitekim, 765 s. mülga TCK'da bulunmamasına rağmen, çevreyi kirlenme sonucunu doğuran belirli ağırlıktaki fiiller yeni TCK'da suç olarak tanımlanmıştır (m. 181, 182, 183).

Keza, daha önce mevcut olan birtakım hukuki değerlerin bugün artık bu özelliklerini yitirdiği söylenemez.

Belirli haksızlıklar daha önce suç olarak tanımlanmış iken, kanun koyucunun izlediği suç siyaseti mülâhazasıyla bugün suç olmaktan çıkarılmış olabilmektedir. Örneğin sosyal endişeye bağlı olarak belirli süreyi (on haftayı –TCK, m. 99–) aşmayan hamileliğin durdurulması (kürtaj) ceza yaptırımını gerektirmemektedir. Ancak, kanun koyucunun bu tercihten, ana rahmine düşüşünden itibaren örneğin on haftalık süre zarfında ceninle ilgili olarak hayat hakkının varlığından söz edilemeyeceği sonucu çıkarılamaz.

Keza, kanun koyucunun izlediği suç siyasetinin gereği olarak bugün TCK'da zina suçuna yer verilmemiştir. Ancak, bu tercihten artık evlilik birliğinde eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğünün olmadığı ve dolayısıyla ailenin bir hukuki değer olmaktan çıkarıldığı sonucu çıkarılamaz. Aksine, evlilik birliğinde eşlerden birinin **zina** etmesi, **hukuka aykırı** bir **fiil** olarak boşanma sebebi oluşturmakla birlikte (22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, m. 161), suç olarak tanımlanmış değildir.

765 s. mülga TCK'nın 422. maddesinde erkeklerin kadın kılığına girerek örneğin kadınlar hamamına girmesi ve keza, 423. maddesinde “*alacağım diye kandırıp kızlık bozma*” fiilleri suç olarak tanımlanmıştı. Söz konusu Kanundan örnek olarak seçilen bu suç tanımlarına, ceza hukuku tekniğine uygun düşmediği için, yeni TCK'da yer verilmemiştir. Ancak bundan, hukuki değerlerin değişkenlik özelliğine sahip olduğu sonucu çıkarılamaz.

Keza, yapılan yeni kanuni düzenlemelerde, izlenen suç siyaseti gereğince, bazı fiillerin suç olmaktan çıkarılıp kabahat olarak tanımlanmasından ya da bir suçun cezasının artırılmasından veya azaltılmasından, hukuki değerlerin değişkenlik özelliğine sahip olduğu sonucu çıkarılamaz.

¹¹⁹ Ünver, bu bağlamda hukuki değerlerin “*hiyerarşik özelliği*”nden söz etmektedir (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 503 vd.).

¹²⁰ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 509, 795 vd.

¹²¹ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 505.

cedeki bir hukuki değer ilişkini olduğu konu feda edilmektedir (konutun kapısı kırılmaktadır).

Bir suçun işlenmesiyle mutlaka bir hukuki değer ihlal edilmektedir. Ancak her hukuki değer ihlali sonucunu doğuran fiil, suç oluşturmaz. Haksızlık teşkil eden fiillerden ancak bir kısmı suç olarak tanımlanmaktadır. Kanunkoyucu, izlediği suç siyaseti gereği olarak, ancak belirli haksızlıkları suç olarak tanımlamaktadır.^{122,123}

Yeni TCK'nın sisteminde esas alınan suç teorisinde suçun unsurları üçe ayrılmaktadır: 1) Maddi unsurlar, 2) Manevi unsurlar, 3) Hukuka aykırılık unsuru. Bu sistemde, kusurluluk, suçun bir unsuru değildir. Kusurluluk, işlediği suç dolayısıyla fail hakkında bulunulan bir değerlendirme yargısıdır.

¹²² Anayasa Mahkemesi, bazı durumlarda, görev ve yetki sınırını aşarak, kanun koyucunun suç olarak tanımladığı bir haksızlığı, suç olmaktan çıkarma yönünde kararlar vermiştir. Şöyle ki, Türk Medeni Kanunu, kayıt dışı evliliğe ve birden fazla kadınla evlenmeye izin vermemektedir. Anayasa Mahkemesi, verdiği bir kararla, “imam nikahı” tabir edilen bir yöntemle, evli olan erkeğin birden fazla kadınla cinsel birliktelik yaşamasının yolunu açmıştır: Anayasa Mahkemesi, 27.5.2015, E. 2014/36, K. 2015/51 (RG: 10 Haziran 2015-29385).

¹²³ Anayasa Mahkemesine göre, bir fiilin suç olarak tanımlanıp tanımlanmaması ve suç olarak belirlenen fiillerin karşılığında hangi cezaların ne ölçüde uygulanabileceği, “*Anayasa'nın konuya ilişkin kuralları başta olmak üzere, ceza hukukunun ana ilkeleri ile ülkenin genel durumu, sosyal ve ekonomik hayatın gereksinimleri göz önüne alınarak saptanacak ceza politikasına göre belirlenir. Bu nedenle Yasa koyucunun ceza politikasının, öncelikle Anayasa'nın 2. maddesinde nitelikleri, 5. maddesinde de temel amaç ve görevleri belirtilen hukuk devleti ilkesine ve anılan maddelerde yer alan adalet ilkesine ve 38. maddedeki güvencelere uygun olması gerekir. Bu doğrultuda ceza önlemiyle toplumsal barışı amaçlayan Anayasa, suçların niteliği, işlenme biçimi ve kamu düzeni için yarattığı tehlikeyi gözetenek ne miktar ceza verileceğinin ve hangi ceza tedbirlerinin ne yolda uygulanacağını saptanmasını yasa koyucuya bırakmıştır. Yasaların kamu düzeninin kurulması ve korunması, kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereğidir.*”: Anayasa Mahkemesi, 27.9.2006, E. 2004/63, K. 2006/94 (RG: 24 Mayıs 2007-26531). Ayrıca bkz. Anayasa Mahkemesi, 18.7.2001, E. 2001/4, K. 2001/332 (RG: 27 Ekim 2001-24566); Anayasa Mahkemesi, 17.11.2011, E. 2010/115, K. 2011/154 (RG: 17 Mart 2012-28236); Anayasa Mahkemesi, 10.4.2013, E. 2013/14, K. 2013/56 (RG: 10 Aralık 2013-28847); Anayasa Mahkemesi, 14.1.2015, E. 2014/116, K. 2015/4 (RG: 29 Nisan 2015-29341); Anayasa Mahkemesi, 12.11.2015, E. 2015/26, K. 2015/100, pn. 6 (RG: 11 Aralık 2015-29559); Anayasa Mahkemesi, 26.5.2016, E. 2015/108, K. 2016/46, pn. 12 (RG: 13 Temmuz 2016-29769); Anayasa Mahkemesi, 2.5.2018, E. 2017/169, K. 2018/42, pn. 10 (RG: 7 Haziran 2018-30444).

§14. Suçun Maddi Unsurları

Her bir suçun kanunî tanımında yer alan unsurlar, maddi ve manevi olmak üzere, iki ana grupta toplanmaktadır. Bu itibarla, suçun yapısal unsurlarının açıklanmasında bu maddi ve manevi unsurlar ayırımı esas alınacaktır.

I. Bir Haksızlık Olarak Fiil

Suç ve evleviyetle haksızlık teşkil eden bu fiil, bir insan hareketidir. Fiil, kanunla muayyen suçlara¹²⁴ takaddüm etmekle beraber, hukuki bir perspektifle tetkike tabi tutulacaktır¹²⁵. Fiil, aralarında esaslı mahiyet farkları mevcut olmakla birlikte, kasten veya taksirle işlenen, icraî veya ihmalî bütün haksızlıkların esasını teşkil etmektedir. Her ne kadar *fiil* kavramına ontolojik bir perspektifle yeknesak bir açıklama getirmek kabil değilse¹²⁶ de; bu kavramın, suç teorisine ilişkin açıklamalarda esas alınması gerekir¹²⁷.

Fiil icraî davranışla işlenebileceği gibi, ihmalî davranışla da işlenebilir. Ancak belirtmek gerekir ki, icraî davranış, doğal bir olgu olduğu halde, ihmalî davranışın esasını normatif bir değerlendirme oluşturmaktadır. Bu bakımdan ihmalî suçlara ilişkin açıklamaların, icraî davranışa ilişkin açıklamalar tamamlandıktan sonra ayrıca yapılması gerekmektedir.

Genel olarak, *fiili* şu şekilde tarif edebiliriz: Fiil, *kışının iradesiyle hakim olduğu, belli bir neticeyi gerçekleştirmeye matuf ve haricî dünyada cereyan eden bir davranıştır*¹²⁸.

Kanundaki suç tanımında mutlaka bir fiile unsur olarak yer verilmektedir. Hiçbir suç tanımı yoktur ki, kapsamında bir insan fiiline yer verilmiş olmasın. Bu

¹²⁴ Suç, haksızlık teşkil eden bir fiil olmakla beraber; her haksızlık, suç teşkil etmez. Bu itibarla, suç teşkil eden fiiller, ancak muayyen haksızlıklardır. Yani, bir haksızlığın suç teşkil ettiği, önceden meselâ kanunla belirlenmiş, tayin edilmiş olmalıdır (*Kanunîlik prensibi* veya *Ceza Hukukunun teminat fonksiyonu* [MAURACH/ZIPF I, sh. 176]). Ancak, bir fiil, mücerret olarak sadece kanunda tarif edildiği için, kendisine ceza atfedildiği için, haksızlık (ve dolayısıyla, suç) vasfını kazanmaz. Bir fiil daha ziyade kanunen suç olarak tarif edilmeden önce de toplumda hakim olan değer yargılarına göre bir haksızlık teşkil etmelidir. Toplumda hakim olan değer yargılarına göre bir fiil, failinin muaheze edilmesini gerektirecek ölçüde bir haksızlık ifade ediyorsa, bu fiil dolayısıyla toplumdaki hukuk düzeni önemli ölçüde ihlâl edilmekteyse, suç vasfını haiz olacaktır. Bu nedenledir ki, hangi haksızlıkların veya hangi şartlardaki haksızlıkların suç olarak tavsif edilmesi gerektiği, önce *suç siyaseti*yle belirlenecektir. Suç siyaseti mülâhazalarıyla suç olarak tavsif edilen bir haksızlık, ceza hukukunun teminat fonksiyonu gereğince, kanunda muayyen unsurları gösterilerek tarif edilmelidir.

¹²⁵ MAURACH/ZIPF I, sh. 180.

¹²⁶ ROXIN, Claus: *Zur Kritik der finalen Handlungslehre*, in: ZStW 74(1962), sh. 548/549.

¹²⁷ MAURACH/ZIPF I, sh. 179/180, 185, 186.

¹²⁸ MAURACH/ZIPF I, sh. 175, 185. Fiil kavramı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. GÖKTÜRK, Neslihan: *Fikri İctima (Suçların İctimai)*, Ankara, 2013, sh. 29 vd.

fiil, herhangi bir insan davranışı olmayıp, bizatihî haksızlık teşkil eden bir insan davranışıdır. Bu itibarla, suç teorisinde söz konusu edilen fiil, bir suçun tarifinde yer alan ve esas itibarıyla *haksızlık* teşkil eden bir fiildir.

İnsan davranışına fiil özelliğini kazandıran, bunun bir irade ürünü olması ve belli bir amaca matuf olarak gerçekleştirilmesidir¹²⁹ (gaî hareket teorisi).

İnsan davranışının belli bir amaca yönelik olarak gerçekleşmesi, ona fiil vasfını kazandırır.

Fiil ehliyeti açısından insanın sahip olduğu en önemli vasıf, davranışlarını belli bir gayeye doğru yönlendirebilme yeteneğidir; bir başka ifadeyle, davranışlarının, yönlendirici iradenin ürünü olmasıdır¹³⁰.

Fiil niteliğini taşıyan insan davranışının bir özelliği, bunun irade ürünü olmasıdır. Ancak, bu irade, kusurluluk ve dolayısıyla, sorumluluk için aranan irade değildir. Başka bir deyişle, bu irade kişinin muaheze edilmesini gerektiren bir irade değildir. Bu itibarla, cebir veya tehdide maruz kalan kişinin davranışı da fiil niteliğini taşımaktadır. Burada zorlanmış da olsa, kişiye izafe edilen bir irade vardır. Cebir veya tehdide maruz kalan insanın iradesi mutlak surette devre dışı bırakılmamıştır.

Ancak, işaret etmek gerekir ki, insandan kaynaklanan her davranış, fiil özelliğini taşımamaktadır. *Fiil ehliyetine*¹³¹ sahip bir yaratık olarak *insandan* kaynaklanan her davranış, fiil vasfını haiz değildir (*Fiilin sınırlama fonksiyonu*).

Bazı insan davranışları, iradenin mutlak bir şekilde devre dışı kalması itibarıyla, fiil olarak nitelendirilemezler. Binaenaleyh, *mutlak* bir *kuvvete* (vis absoluta) maruz kalan kişinin iradesi tamamen devre dışı kaldığı için, insanın bu haldeki davranışları fiil vasfını haiz değildir¹³². Mekanik olarak karşı konulamayan bu kuvvet, bir insandan kaynaklanabileceği gibi, tabî bir kuvvet, tabî bir olay mahiyeti de arzedebilir. Fakat, *cebre*, *zorlayıcı kuvvete* (vis compulsiva) veya *teh-*

¹²⁹ MAURACH/ZIPF I, sh. 175, 185.

¹³⁰ ÖZGENÇ, İzzet. *Tüzel Kişinin Sorumluluk Ehliyeti- Anayasa Mahkemesi'nin Bir kararı Üzerine Düşünceler*, Reha Poroy'a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 1995, sh.319 vd.

¹³¹ Burada kullandığımız “*fiil ehliyeti*” kavramı, Alman hukukçuların kullandıkları “*Handlungsfähigkeit*” (“hareket yeteneği”) kavramına tekabül etmektedir. Medenî hukuk sahasındaki hak ehliyeti - “fiil ehliyeti” ayırımında kullanılan “Fiil ehliyeti” kavramı kanaatimizce isabetli değildir. Hukuki kavramlar arasında karışıklığa, teşevvüşe mahal vermemek için, medenî hukuk sahasında “fiil ehliyeti” kavramı yerine, *hukuki muamele ehliyeti* denmesi daha uygun olacaktır (Bu hususta geniş açıklama için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Tüzelkişinin Sorumluluk Ehliyeti. Anayasa Mahkemesi'nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler*, Reha Poroy'a Armağan, 1995, sh. 325 vd.).

¹³² GÜLŞEN, Recep: *Ceza Hukukunda Sorumluluğu Kaldıran Nedenlerden Kaza, Mücbir Sebep, Cebir ve Tehdit*, Ankara 2007, sh. 121, 139.

dide maruz kalan kişinin bu haldeki hareketleri, iradesi zorlanmış olmasına rağmen, fiil niteliğindedir¹³³. İradesi zorlanmış da olsa ve kusur açısından esas alınmasa bile, bu durumdaki kişi bir harekette bulunurken iradesi vardır ve dolayısıyla, bu hareketi hukuki anlamda fiil teşkil etmektedir.

Zorunluluk (zaruret) halinde gerçekleştirilen insan davranışı, zorlanmış da olsa, bir iradeye dayanan fiil mahiyetindedir. Fiilin varlığından bahsedebilmek için aranan irade, değerden yoksun bir iradedir¹³⁴. Yani, bu hallerde zorlanmışlık nedeniyle faile kusur isnadı kabil değilse de, bu fiil dolayısıyla failin muaheze edilmesi mümkün değilse de; iradeye dayanan bir fiil yine de mevcuttur. Zorlanmışlık nedeniyle kusurun söz konusu olamayacağı halle; irade ürünü olmayan ve dolayısıyla, fiil vasfını haiz olmayan insan davranışı arasındaki sınır; her somut (müşahhas) olayın şartları dikkate alınarak tayin edilecektir.

Keza, refleks hareketleri, fiil vasfını haiz değildir. Refleks, iradî etkileşim olmaksızın vücudun gösterdiği reaksiyondur. Bu halde, irade tamamen devre dışıdır.

Buna karşılık, anî karar sonucu gerçekleştirilen insan davranışları (affekt hareketler), fiil vasfını haizdirler. Bu fiillerin en belirgin özelliği, kişiyi bu fiili işlemekten alıkoyacak direnme imkânının zayıflamış olması veya tamamen yok olmasıdır. Bu itibarla, söz konusu davranışlar fiil niteliğini haiz olmakla beraber, irade kabiliyeti üzerindeki etkisi itibarıyla, bu hallerde failin kusurunun mevcut olup olmadığı tetkik edilecektir¹³⁵.

Motorlu taşıt sürücülerinin vasıta kullanma esnasındaki davranışları da fiil vasfını haizdir. Bu esnadaki davranışlar, aktüel şuur tarafından yönlendirilmemektedirler. Tabir caizse, bu durumda “*yarı otomatik*” insan davranışı söz konusudur. Ancak, bu tür bir davranış, hakim olunabilir bir mahiyet arzetmesi itibarıyla, yine fiil olarak telâkki edilecektir¹³⁶.

Tam bir şuur yokluğunda gerçekleştirilen insan davranışları fiil vasfını haiz değildir. Buna karşılık, şuur bulanıklığı veya şuur bozukluğu hallerindeki davranışlar, fiil vasfını haizdirler. Ancak, bu hallerde kişinin kusurundan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Buna göre, meselâ derin uyku halinde, epileptik nöbet sırasında¹³⁷ veya hipnotik telkin altında¹³⁸ bulunulan davranışlar, fiil niteliğinde değildirler.

¹³³ Bu kavramlar hakkında geniş bilgi için bkz. SÖZÜER, Adem: *Tehdit Suçu*, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LIV, yıl 1991-1994, sayı 1-4, sh. 125 vd.

¹³⁴ MAURACH/ZIPF I, sh. 188.

¹³⁵ Affekt hareketi “takaddüm eden fiil” [Ingerenz] esasına dayanarak izah eden görüş için bkz. BEHRENDT, Hans-Joachim: *Affekt und Vorverschulden*, 1983, sh. 77 vd.

¹³⁶ MAURACH/ZIPF I, sh. 189; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 202, dn. 31; WESSELS[19], sh. 25.

¹³⁷ MAURACH/ZIPF I, sh. 189; JESCHECK, Lehrbuch(4), 202; ARTUK, Emin: *Suç Genel Teorisi*, in: Ceza Hukuku El Kitabı, 1989, sh. 195.

¹³⁸ WESSELS [19], sh. 26.

İnsandan kaynaklanan davranışın fiil niteliğini taşıyabilmesi için, davranışı gerçekleştiren kişinin mutlaka kusur yeteneğinin var olması gerekmez. Bu nedenle, kusur yeteneğine sahip olmayan örneğin küçük yaşta bulunan kişilerin davranışları da fiil niteliğini taşımaktadır. Bir insan, fiil ehliyetine sahip olmakla birlikte, kusur yeteneğine sahip olmayabilir¹³⁹. Bu itibarla; kusur yeteneğinin var olup olmadığına bakılmaksızın *prensip olarak* her insanın fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul etmek gerekir. Failin kusur yeteneğinin mevcut olup olmadığı ve bunun sorumluluk üzerindeki etkisi, ilk defa kusurluluk bahsinde tetkik edilecektir.

Fiil, mutlaka dış dünyada tezahürü olan bir insan davranışdır. Bu itibarla, salt düşünce, hiçbir zaman ceza hukukunun konusu olamaz ve hatta, sorumluluk sebebi teşkil etmez. Ancak, bu fiilin bir el kol hareketi şeklinde olması gerekmez. Bir düşüncenin sözle ya da herhangi bir surette ifade edilmesi de fiil niteliğini taşımaktadır.

Bu itibarla, insanların suç işlemeye alenen tahrik edilmesi (m. 214), toplum kesimlerinin birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edilmesi (m. 216, f. 1), kişilerin birbirlerinin şeref ve haysiyetine tecavüz teşkil eden sözler sarfetmesi (m. 125) hallerinde insana izafe edilen bir davranış ve dolayısıyla, fiil mevcuttur.

Hukukta fiil söz konusu olduğunda, mutlaka insandan kaynaklanan bir davranışın var olması gerekir. Hayvana izafe edilen davranışlar, hiçbir zaman hukuki anlamda fiil niteliğini taşımazlar.

Hayvana nezaret etme yükümlülüğü altında bulunan kişinin hayvanın verdiği zararlardan sorumlu olmasının nedeni, kişinin hayvan üzerindeki bu gözetim yükümlülüğünün gereklerine göre hareket etmemesidir (ihmalî davranış). Hayvanın başkasına zarar vermesi, hukuki anlamda fiil niteliğini taşımamaktadır.

Keza, bir suçun işlenmesinde hayvan bir araç olarak kullanılmış olabilir. Meselâ, bir köpeğin bir başkasına saldırtılmasında, ceza hukuku açısından önem arzeden davranış, köpeğin başkasına zarar veren davranışı değil, bu köpeği başkası üzerine saldırtan kişinin davranışı yani fiilidir.

Bu bağlamda **fiil ile hareket arasındaki ilişkiye** ve **farka** işaret etmek gerekir. Fiil, ancak insana izafe edilen bir davranış olmakla birlikte, hareket ile insan arasında zorunlu bir bağ yoktur. İnsan dışı varlıklara da hareket izafe edilebilir.

¹³⁹ Şöyle ki; 8 yaşındaki bir çocuk, insan olması itibarıyla, fiil ehliyetine sahiptir; ancak, işlediği fiilin anlam muhtevasını idrak kabiliyetine henüz sahip olmadığı için, henüz fârik ve mümeyyiz olmadığı için, kusur ehliyeti mevcut değildir. (*Fiil ehliyeti* ve *kusur ehliyeti* kavramları hakkında bkz. YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 202; BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 13, kn. 13 vd., § 19, kn. 2). Bu açıklamalarımız karşısında; *Alacakaptan*'ın şu düşüncesinin doğru olmadığı açıkça anlaşılabilmektedir: "... *anlama ve isteme yeteneğine sahip bulunmayan bir kimsenin kasd ya da taksirle hareket etmesi düşünülemez. Onun hareketi hukuk açısından önem arz etmez.*" (ALACAKAPTAN, Suçun Unsurları, sh. 108).

Örneğin, suyun akması, rüzgarın etkisiyle yaprağın sallanması, yer çekimi nedeniyle yukarıdan bırakılan cismin yere düşmesi gibi durumlarda hareket mevcuttur. Keza, mekanik bir aracın hareketi, bu bağlamda tezekkür edilebilir. Hayvanlara da hareket izafe edilebileceği, izahtan varestedir.

Fiil, kasten işlenebileceği gibi; taksirle de işlenebilir. Bundan çıkaracağımız ilk sonuç; suç ve evleviyetle haksızlık teşkil eden fiilin *manevi unsuru*nu oluşturan **kast ve taksirin**, birer kusurluluk şekilleri olmayıp, bu **haksızlığın birer işleniş tarzından** ibaret olduklarıdır¹⁴⁰. Kast ve taksirle işlenen fiillerin mahiyetinde farklılıklar mevcuttur. Kast işlenen haksızlıklar, birer *gaî* fiil olmaları itibarıyla, ontik bir mahiyet arzetmektedir. Taksirli haksızlıklar ise, ontik vakıanın yanısıra, mutlaka bir değerlendirme unsuru (objektif özen yükümlülüğüne aykırılık) ihtiva etmektedir. Kast ve taksiri birer kusurluluk şekli olarak kabul etmemekle beraber, kast ve taksirle işlenen haksızlıkların işlenişinde kusurun arzedeceği özelliklerin de birbirinden farklı olduklarını belirtmek gerekir.

Kasten işlenen haksızlıklarda yönlendirici irade, hukukun önem atfettiği neticeye, yani suçun kanunî tanımındaki neticeye yöneliktir. Buna karşılık, taksirle işlenen haksızlıklarda ise, söz konusu irade, hukuken önem arzetmeyen bir neticeye yöneliktir. Ancak, hukuken kişiye tahmil edilen özen yükümlülüğüne aykırı davranıldığı için, hukukun önem atfettiği bir başka netice (de) gerçekleşmektedir.

Suçun kanunî tarifinde fiilin tanımlanışına göre suçlar çeşitli şekillerde tasnife tabi tutulabilir. Bu bağlamda suçlar, tek veya çok hareketli suçlar, serbest hareketli suçlar, bağlı hareketli suçlar, seçimlik hareketli suçlar ve mütemadi (kesintisiz) suçlar olarak bir ayırma tabi tutulabilir.

A. Tek veya Çok Hareketli Suçlar

Kanunda yer alan suç tanımlarında bazen bir tek fiile yer verilir. Meselâ, kasten öldürme suçu, (m. 81) “Bir insanı kasten *öldüren* kişi ...”; hırsızlık suçu (m. 141) “... başkasına ait taşınır bir malı ... bulunduğu yerden *alan* kimse ...” şeklinde tanımlanmıştır.

Dikkat edilmelidir ki, fiilin tekliği veya çokluğu, doğal anlamda değil, hukuki anlamda anlaşılmalıdır. Örneğin kasten yaralama suçunun işlenmesi sırasında kişinin vücuduna birkaç yumruk veya birkaç defa sopayla vurulması halinde, doğal anlamda fiil sayısı birden fazladır. Keza, kullanılan farklı anlamdaki sözlerle kişiye hakaret edilmesi halinde, sarfedilen her bir söz, doğal anlamda ayrı fiil niteliği taşımaktadır. Ancak, bu gibi durumlarda hukuki anlamda tek bir fiilin işlendiği kabul edilmektedir. Doğal anlamda birden fazla olan bu hareket-

¹⁴⁰ Baumann/Weber/Mitsch da, kast ve taksirin artık birer kusur şekli olarak anlaşılmadığı görüşündedirler (BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 18, 25). Ayrıca bkz. KEÇELİOĞLU, Elvan: *Taksirli Suçun Dogmatigi*, Ankara 2015, sh. 50.

ler, ancak işlenen suçun haksızlık muhtevasının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaktadır¹⁴¹.

Buna karşılık, bazı suçlara ilişkin kanunî tariflerde bir tek fiilden değil, birden fazla fiilden söz edilmektedir. Meselâ, dolandırıcılık suçunda (m. 157) maddi unsur kapsamında hile teşkil eden davranışlarla birlikte bir yarar sağlama; yağma suçunda (m. 148) cebir veya tehdidin yanı sıra, yarar sağlama fiillerine yer verilmiştir. Keza, yağma suçunun nitelikli şekli olarak, bu suçun konutta işlenmesi halinde, (m. 149, f. 1, bent d), birden fazla fiile yer verilmiştir. Yine, Kanunda “*bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi ... cezalandırılır*” demek suretiyle, özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, hem sahtecilik hem de kullanma fiilinin işlenmesi gerekmektedir (m. 207, f. 1). Bu gibi durumlarda *çok hareketli suç* söz konusudur¹⁴².

Kanunî tarifine göre birden fazla hareketin gerekli olduğu suçlarda, bu hareketlerin hepsi icraî nitelikte olabileceği gibi; bunlardan bir kısmı icraî, bir kısmı ihmalî hareketler şeklinde de tezahür edebilir¹⁴³. Örneğin ikna suretiyle irtikâp suçu, kamu görevlisinin “*görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna*” etmesiyle ya da, “*kişinin hatasından yararlanarak*” işlenebilir (m. 250, f. 1, 2).

B. Serbest Hareketli Suçlar

Bir suçun kanunî tarifinde o suçu oluşturan fiilin ne tarz bir fiil olduğu konusunda bir özelleştirmenin yapılmadığı suçlara serbest hareketli suçlar denmektedir. Meselâ kamu görevinin kötüye kullanılması suçunda suçu oluşturan fiiller kanunda somut bir şekilde belirlenmemiştir. Bu suçun oluşabilmesi için, kasıtlı olarak kamu görevinin gereklerine aykırı hareket etmek yeterlidir (m. 257).

Keza, kanunda belli bir suçun temel şekli tanımlanırken hareketin icra tarzı konusunda herhangi bir özelleştirmeye gidilmemektedir. Burada önemli olan, hu-

¹⁴¹ “... Ceza Genel Kurulunun 2.3.2010 gün ve 259-47 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, bir **fiilin hukuki anlamda tekliği ile doğal anlamda tekliği** kavramlarının aynı olmadığı gözardı edilmemelidir. Bazen suçların işlenmesi sırasında doğal olarak birden fazla hareket yapılmakta ise de, ortaya konulan bu davranışlar, suçun kanuni tanımında yer alan hukuki anlamda “*tek bir fiil*” oluşturmaktadır. Örneğin; kasten yaralama suçunda, failin sanığa önce yumruk, sonra sopayla, sonra da tekmeyle birçok kez vurması durumunda doğal anlamda birçok hareket bulunmakla birlikte, hukuksal anlamda bu hareketlerin tamamı tek bir kasten yaralama fiilini oluşturacaktır.” **CGK, 22.10.2013**, E. 2013/14-379, K. 2013/427.

¹⁴² İÇEL, Kayıhan: Suçların İctimai. Genel Bilgiler - Fikrî İctima - Mütessesil Suçlar - Görünüşte İctima, İstanbul, 1972, sh 204 vd.; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/ MAH-MUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 2. Kitap, 2. bası, İstanbul 2000, sh. 469.

¹⁴³ EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 256.

kuken tasvip edilmeyen bir neticenin oluşumuna kasten sebebiyet vermektir. Meselâ “*Bir insanı kasten öldüren kişi ...cezalandırılır.*” (m. 81).

Bu suçlara *serbest hareketli suçlar* denmektedir.

C. Bağlı Hareketli Suçlar

Buna karşılık, bir suçun kanunî tanımında hangi tür hareketlerle suçun icra edilebileceği belirtilmiş ise, bu durumda *bağlı hareketli suçlardan* söz edilmektedir. Meselâ irtikâp suçunun oluşabilmesi için, kamu görevlisinin, “*görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar*” ya da “*görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna*” etmesi gerekir (m. 250, f. 1, 2).

Bir suçun temel şekli serbest hareketli bir suç olmakla beraber, nitelikli şekli bağlı hareketli suç görüntüsü arz edebilir. Meselâ, kasten öldürme suçunun “*yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle*” işlenmesi (m. 82, f. 1, bent c); hırsızlık suçunun “*elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle*” (m. 142, f. 2, bent b), “*doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak*” (m. 142, f. 2, bent c), “*haksız yere elde bulundurulmuş veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle*” (m. 142, f. 2, bent d), “*bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle*” (m. 142, f. 2, bent e), “*tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak*” (m. 142, f. 2, bent f) işlenmesi, bu suç açısından faile daha ağır bir cezanın verilmesini gerektiren bir *nitelikli unsur* oluşturmaktadır¹⁴⁴.

D. Seçimlik Hareketli Suçlar

Bazı suçların kanunî tanımlarında suçun icrasının birden fazla alternatif hareketle gerçekleşebileceği belirtilmektedir. Meselâ Kanunda “*uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, ... cezalandırılır.*” (m. 188, f. 1) ya da “*uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, ... cezalandırılır.*” (m. 188, f. 3) demek suretiyle bir seçimlik hareketli suç oluşturulmuştur. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin izinsiz olarak imal edilmesi veya yurt dışında üretilmiş uyuşturucu maddenin izinsiz olarak ülkeye sokulması halinde suç oluşacaktır. Keza, kişinin, bir başkası tarafından işlenen suçtan elde edilen eşyayı kasten kabul etmesi veya satın alması halinde TCK'nın

¹⁴⁴ İşaret etmek gerekir ki, *Soyaslan*, yeni TCK'da bağlı hareketli suç bulunup bulunmadığının “tartışmaya açık” olduğu fikrindedir (SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 272).

165. maddesindeki suç oluşacaktır. Aynı şekilde, iade ve belli bir surette kullanılmak üzere kendisine verilen eşyayı “*kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi,*” güveni kötüye kullanma suçunu işlemiş olur (m. 155).

Bu seçimlik hareketlerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde suç tamamlanmış olur. Suçun tamamlanması için seçimlik hareketlerden herhangi birinin gerçekleşmesi yeterlidir.

Seçimlik hareketlerden birkaçının veya hepsinin gerçekleşmesi halinde dahi suç bir defa işlenmiş kabul edilmektedir. Bu hareketlerden birkaçının veya hepsinin gerçekleşmiş olması dolayısıyla suçun birden fazla işlenmiş olduğu ileri sürülemeyecektir.

Seçimlik hareketlerden meselâ birinin tamamlanmış, diğerinin ise teşebbüs aşamasında kalmış olması durumunda, tamamlanmış olan harekete itibar edilerek suçun tamamlanmış olduğunu kabul etmek gerekir¹⁴⁵.

Dikkat etmek gerekir ki; seçimlik hareketli suçlarda suçun konusu değişmemektedir. Bu seçimlik hareketlerden her biri **aynı konu** üzerinde, *aynı konu* ile ilgili olarak gerçekleşebilmektedir. Bu itibarla, seçimlik hareketli suçtan söz edebilmek için seçimlik hareketlerin *aynı konuya* ilişkin olması gerekir. Burada konunun ayniyetinden kasıt, tür itibarıyla ayniyet değil, **nesnel olarak ayniyettir**. **Tür itibarıyla aynı olmakla birlikte, nesnel olarak farklılık söz konusu ise, artık seçimlik hareketli suçtan söz edilemez.** Örneğin bir parti uyuşturucu maddeyi satın alan, başka bir parti uyuşturucu maddeyi ise nakleden kişi, iki ayrı suç işlemiş olmaktadır. Her ne kadar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (m. 188, f. 1, 3) seçimlik hareketli suç ise de, satın alma ve nakletme fiillerinin konusunu oluşturan uyuşturucu maddenin nesnel olarak aynı olmaması halinde, iki ayrı suçun varlığını kabul etmek gerekir.

Suç tanımına ilişkin kanun maddesinde birden fazla harekete seçimlik olarak yer verilmiş olmakla birlikte, bunların ilişkin olduğu konuların birbirinden farklı olması halinde, artık seçimlik hareketli suç söz konusu değildir. Özellikle TCK’nın dışındaki kanunlarda yer alan suç tanımlarında bu durumla karşılaşılacaktır. Bu durumda kanun maddesindeki her bir konuya ilişkin hareket ayrı bir suç oluşturmaktadır¹⁴⁶.

¹⁴⁵ “Seçimlik hareketli suçlar, suçun kanuni tanımında gösterilen alternatifli hareketlerden herhangi birisinin işlenmesi ile tamamlanabilen suçlardır. Seçimlik hareketlerin tamamının işlenmesi şart olmayıp, bir tanesinin işlenmesi suçun oluşması için yeterlidir. Seçimlik hareketlerden birkaçı ya da hepsi birlikte işlenmiş olsa dahi tek suç oluşacak, ancak bu durum temel cezanın belirlenmesinde göz önünde tutulabilecektir. Seçimlik hareketlerden birisi tamamlanmış ise diğeri teşebbüs aşamasında kalsa dahi suç tamamlanmış kabul edilecektir. Bu suçlarda, suç tarihi en son seçimlik hareketin yapıldığı tarih olup dava zamanaşımı da bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.”: CGK, **23.6.2015**, E. 2014/11-568, K. 2015/244; CGK, **12.2.2013**, E. 2012/11-1445, K. 2013/54.

¹⁴⁶ Meselâ 765 s. Kanunun 312. maddesinin 1. fıkrasına göre; “*Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya halkı kanuna itaatsizliğe tahrik eden kimse*”

Bu husus, özellikle TCK dışındaki kanunlarda yer verilen suç tanımları ile ilgili olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim, 22.4.2004 tarihli ve 5147 sayılı “Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun”un 39. maddesinde bentler altında, değişik konularla ilgili değişik fiiller tanımlandıktan sonra, “*her bir bentte yazılı fiilleri işleyenler*”in ayrı ayrı cezalandırılacakları hüküm altına alınmıştır.

Suçun konusunun nesnel olarak aynı olması koşuluyla, seçimlik hareketlerden birinin tekrarı halinde dahi suç bir defa işlenmiş sayılacaktır.

Kullanmak fiili, resmi belgede sahtecilik suçunun seçimlik (alternatif) hareketini oluşturmaktadır (TCK, m. 204, f. 1, 2). Keza, çok hareketli suç olan **özel belgede sahtecilik suçunun** maddi unsurunu oluşturan hareketlerden biri, kullanmak fiilidir (TCK, m. 207, f. 1, 2).

İster resmi belgede sahtecilik suçu olsun, ister özel belgede sahtecilik suçu olsun, kullanmak suretiyle işlenen belgede sahtecilik suçunun ne zaman tamamlandığı hususuna açıklık getirmek, özellikle dava zamanaşımı süresinin işleme-ye başlaması bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

5237 s. TCK’nın 207. maddesinin gerekçesinde de açıkça vurgulandığı üzere, “*kullanmadan maksat, bu sahte belgenin herhangi bir hukukî ilişkide veya herhangi bir hukukî işlem tesisinde dikkate alınmasını sağlamaya çalışmaktır.*”¹⁴⁷. Bu açıklamaya rağmen, “kullanmak” fiilinin anlamına açıklık getirmek gerekmektedir.

Örneğin A, adına düzenlediği sahte pasaportu kullanmak suretiyle müteaddit defa yurt dışına çıkış ve yurda giriş yapar.

Bu örnek olayda A, adına sahte bir pasaport düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlemiştir. Bu sahte pasaportun düzenlenmesiyle resmi belgede sahtecilik suçu tamamlanmıştır. Düzenlenen sahte pasaport kullanılmamış olsa bile, suç pasaportun düzenlenme anında tamamlanmıştır. A’nın bu pasaportla yurt dışına çıkması halinde, yeni bir resmi belgede sahtecilik suçu işlenmemektedir. Ancak, bu durumda resmi belgede sahtecilik suçu, söz konusu suçun seçimlik hareketlerinden birini oluşturan kullanma anında bitmiş olmaktadır. Bu durumda

cezalandırılır. Bu fıkra da iki ayrı suç tanımlanmaktaydı. (BAYRAKTAR, Köksal: *Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü*, İstanbul 1977, sh. 207 vd., 227 vd.; ÖNDER, Özel Hükümler[3], sh. 259 vd., 267 vd.). Bunlardan birisi, “*cürüm fiilini övme suçu*”, diğeri ise, “*halkı kanuna itaatsizliğe tahrik etme suçu*”dur. Birincisinde suçun konusu, “*işlenmiş olan somut bir cürüm fiili*”dir; ikincisinde ise, “*muayyen bir kanun ve bu kanuna itaat etmeme fiili*”dir. Ayrıca belirtelim ki, “*cürüm fiilini övme suçu*”, 765 s. TCK’daki tanımlama biçimi itibarıyla “seçimlik” hareketli bir suçtur. Çünkü, bu suç, işlenmiş olan somut bir cürüm fiilini “*övmek*” veya “*iyi gördüğünü söylemek*” suretiyle işlenebilmektedir (Bu iki kavramla ilgili olarak bkz. BAYRAKTAR, Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, sh. 208, 218; ÖNDER, Özel Hükümler[3], sh. 262).

¹⁴⁷ Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin 3 Ağustos 2004 tarihli ve Esas 1/593, Karar 60 sayılı Rapor, in: TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 604 vd.

söz konusu suça ilişkin dava zamanaşımı süresi, sahte pasaportun düzenlendiği andan itibaren değil, kullanıldığı andan itibaren işlemeye başlar.¹⁴⁸

Ancak belirtmek gerekir ki, sahte belgenin müteaddit defa kullanılması halinde, her bir kullanma ayrı bir suç oluşturmamaktadır. Çünkü bu durumda **suçun konusu nesnel olarak aynıdır**. Aynı sahte belgenin müteaddit defa kullanılmış olması halinde, seçimlik hareket olan kullanmanın birden fazla gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, suçun konusu aynı olduğu için resmi belgede sahtecilik suçunun bir defa işlenmiş olduğunu kabul etmek gerekir. Bu gibi durumlarda **dava zamanaşımı süresi, son kullanma tarihinden itibaren işlemeye başlar**^{149,150}.

¹⁴⁸ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 8.5.2012 tarihli ve E. 2012/11-292, K. 2012/184 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda Kahramanmaraş'ın "Afşin İlçesine bağlı ... belde belediyelelerinden, çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve kurumlar olmak üzere değişik kamu kuruluşlarına kurumlararası geçiş için başvuruda bulunan 498 kişi hakkında adı geçen belediyelerde gerçekte çalışmamış oldukları halde, çalışıyorlarmış gibi hizmet belgeleri, sicil dosyaları, işe başlama yazıları, sınav tutanakları, muvafakat tutanakları ve encümen kararları" düzenlenir. Bu kişiler, gerçeğe aykırı olarak düzenlenen belgeleri mesnet göstererek, çeşitli kamu kuruluşlarına geçiş yapmak amacıyla başvuruda bulunurlar.

Bu olayda çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçu işlenmiştir. Bu suçlar, iştirak halinde işlenmiştir. Düzenlenen her bir sahte resmi belgede sahtecilik suçu bakımından dava zamanaşımı süresi, bu suçun seçimlik hareketlerinden **kullanma** olgusunun gerçekleştiği tarihten itibaren, yani düzenlenen sahte resmi belge mesnet gösterilerek kurumlararası geçiş için yapılan başvuru tarihinden itibaren işlemeye başlamıştır.

¹⁴⁹ Aynı şekilde, sahte olarak üretilen özel belgenin müteaddit defa kullanılması halinde, suçun konusu olan sahte belge aynı olduğu için, çok hareketli bir suç olan özel belgede sahtecilik suçunun (TCK, m. 207) bir defa işlenmiş olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Resmi belgede sahtecilik suçunda olduğu gibi, bu durumda da **dava zamanaşımı süresi son kullanma tarihinden itibaren işlemeye başlar**.

¹⁵⁰ **Kullanma, kesintisiz (mütemadi) suç şeklinde de gerçekleşebilir.** Örneğin sahte olarak düzenlenmiş olan sürücü belgesine istinaden araç kullanılarak trafiğe çıkılması halinde, adına sahte sürücü belgesi düzenlenen kişi tarafından araç trafikte kullanıldığı sürece resmi belgede sahtecilik suçu işlenmeye devam edilmektedir. Çünkü kişi bu sahte sürücü belgesine dayalı olarak trafikte motorlu araç kullanmakta ve bu araçla trafikte kalmaya devam etmektedir. Ancak, işaret etmek gerekir ki, sahte olarak üretilmiş olan sürücü belgesinin (buna istinaden trafikte araç kullanılmaksızın) sadece kişinin yanında bulundurulmuş olması halinde, kullanma fiilinin gerçekleştiğinden söz edilemez (Peters CRAMER, in: Schönke, Adolf/Schröder, Horst: *Strafgesetzbuch. Kommentar*, 23. Auflage, München, 1988, § 267, kn. 76).

Keza, sahte olarak üretilmiş olan plaka motorlu araca takılmakla sahte resmi belge kullanılmaya başlanmıştır. Bu plaka araçta takılı olduğu sürece kullanma fiili devam etmekte ve resmi belgede sahtecilik suçu kesintisiz (mütemadi) suç şeklinde işlenmeye devam olunmaktadır.

Kullanmaktan maksat, belgenin ulaşılabilir hale getirilmesidir. Kullanma sonucunda bir başkasının, ilgililerin belgeyi gerçekten algılamış veya görmüş olması gerekli değildir (CRAMER, Schönke/Schröder, §267, kn. 76). Bu itibarla, sahte olarak üretilmiş olan plakanın takıldığı aracın başkaları tarafından görülebilir şekilde trafiğe çıkarılması halinde, kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçu işlenmektedir (CRAMER, Schönke/Schröder, § 267, kn. 76).

Kullanmak suretiyle işlenmiş belgede sahtecilik suçunun varlığı için, sahte belgenin kişilerin belirli bir hukuki durum hakkında yanılmaya sevk edilecek şekilde kullanılması yeterlidir. Belgenin kullanılmasıyla belirli bir kişinin yanıltılmasının hedeflenmiş olması gerekmez

E. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar

Kanunî tarifindeki **fiilin icrası süreklilik arzeden suçlara** mütemadi (kesintisiz) suçlar denmektedir¹⁵¹. Mütemadi suçlarda fiilin icrası bir anda tamamlanamamaktadır. Bu suçlar açısından özellik arzeden husus, neticenin devamı değildir. Bu itibarla, mütemadi suçlarda neticenin süreklilik arzettiği yönündeki “doktriner” görüş¹⁵² doğru değildir.

Meselâ, kasten öldürme suçu, ani suç olmasına karşılık; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu (m. 109), mütemadi bir suçtur. Kasten öldürme suçunda ölüm neticesinin gerçekleşmesiyle suç tamamlanmış olmaktadır. Buna karşılık, mütemadi suçlarda, suçun kanunî tarifindeki fiilin icrasına devam edilmektedir. Keza, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (m. 220, f. 2, 2), girilen konuttan çıkmamak suretiyle işlenen konut dokunulmazlığının ihlâli suçu (m. 116, f. 1), karşılıksız yararlanma (m. 163), uyuşturucu veya uyarıcı maddenin imali, nakledilmesi, depolanması (m. 188, f. 3), hatta işkence (m. 94) veya eziyet (m. 96) suçları bir mütemadi suçtur.

Bir suç, esas itibarıyla ani bir suç olmakla beraber, bazı durumlarda mütemadi (kesintisiz) suç şeklinde de işlenebilmektedir. Meselâ, hırsızlık suçu ani bir suçtur. Ancak, petrol boru hattına yapılan bağlantı ile süreklilik arzedecek şekilde petrol çekilerek işlenen hırsızlık, mütemadi bir nitelik taşımaktadır (m. 142, f. 3).

Mütemadi suçun işlenmesine icraî bir davranışla başlanıp, ihmalî davranışla devam edilebilir. Meselâ, bir yere hapsedilmek suretiyle kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmasıyla suç işlenmeye başlanmıştır; hürriyeti tahdit edildiği sürece bu kişinin serbest bırakılmaması suretiyle suçun icrasına devam edilmektedir (m. 109). Keza, bir kimsenin konutuna rızasına aykırı olarak giren kişi orada bulunduğu süre zarfında bu suçu işlemeye devam etmektedir (m. 116).

Mütemadi suça teşebbüs, özellik taşımaktadır. Mütemadi suçlarla ilgili olarak **suçun tamamlanması ve bitmesi** kavramları kullanılmaktadır. Mütemadi suç

(CRAMER, Schönke/Schröder, § 267, kn. 78). Sahte olarak üretilmiş olan plakanın takıldığı motorlu aracın trafiğe çıkarılmış olması, sahte olarak üretilmiş avukatlık ruhsatına dayalı olarak avukatlık mesleğinin icra edilmesi, sahte olarak üretilmiş ruhsata istinaden eczacılık mesleğinin icra edilmesi, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

“**Kullanmak**”tan söz edebilmek için, sahte belgenin bir hukuki işlem tesisine dayanak olarak gösterilmesi yeterlidir. Sahte olarak üretilmiş olan belge dayanak gösterilerek mahkemelerde dava açılması, açılmış olan bir davada sahte olarak üretilmiş olan bir belgenin delil olarak ibraz edilmesi, bu duruma örnek olarak gösterilebilir (ERMAN, Sahir: Erman/Özek, *Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar* (TCK. 316-368), İstanbul, 1996, sh. 527).

¹⁵¹ AKBULUT, Genel Hükümler, sh. 269.

¹⁵² DÖNMEZER/ERMAN I, no. 519; HAKERİ, Ceza Hukuku, 5. bası, sh. 131. *Hakeri*’nin doktriner dayanağı olmayan bu görüşte hâlâ “sebat” ettiği görülmektedir (HAKERİ, Hakan: *Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, 18. bası, Ankara 2015, sh. 180 vd.).

tamamlanıncaya kadar, suça teşebbüse ilişkin hükümler uygulanabilir. Buna karşılık suç tamamlanmış olmakla birlikte, icrasına devam ederken failin elinde olmayan nedenlerle icrasının sona erdirilmiş olması halinde, artık teşebbüse ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu durumda suç tamamlanmıştır. Örneğin elektrik enerjisinin tüketilmesi suretiyle işlenen karşılıksız yararlanma suçunun (TCK, m. 163, f. 3) icrasına, durumun anlaşılması üzerine son verildiğinde, suç teşebbüs aşamasında kaldığı için değil, tamamlanmış olduğu için cezaya hükmedilmelidir.

Mütemadi suçların bir diğer özelliği, iştirak konusunda ortaya çıkmaktadır. Mütemadi suç işlenmeye devam ettiği sürece, o suçun icrasına iştirak etmek mümkündür¹⁵³. Bu itibarla, mütemadi suç tamamlanmış olmakla birlikte, icrasına devam ederken, bir başkası tarafından bu suçun işlenişine iştirak edilmesi mümkündür ve bu durumda suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır.

Keza, mütemadi suçu işleyen kişiye karşı, suçun icrası devam ettiği sürece, meşru müdafada bulunulabilir.

Mütemadi suçların ceza ve ceza muhakemesi hukuku bakımından da birtakım önemli sonuçları vardır. Meselâ, suçun işlendiği yer ve zamanın, şikayet veya dava zamanasını süresinin belirlenmesinde, temadinin devam edip etmediğine bakılacaktır.

II. Netice

Suçun maddi unsurlarından ikincisini, netice oluşturmaktadır. Belirtmek gerekir ki, netice, fiilin bir alt unsurunu değil, fiilden ayrı olarak, suçun maddi unsurlarından birini oluşturur. Bu bakımdan, yeni TCK'ya hakim olan suç teorisinde, her suçta mutlaka bir netice vardır şeklindeki klasik anlayış terkedilmiştir. Bunun sonucu olarak, benimsenen sistemde, klasik suç teorisinde olduğu gibi “neticesi harekete bitişik” veya “neticesi hareketten ayrı suç” ayırımından artık söz edilemez¹⁵⁴.

Netice icra edilen fiilin dış dünyada meydana getirdiği değişikliktir. Ancak, icra edilen fiilin dış dünyada meydana getirdiği her değişiklik değil, sadece suçun kanunî tarifinde unsur olarak yer alan değişiklik ceza hukuku açısından önem taşımaktadır.

¹⁵³ ROXIN, Lehrbuch(1), sh. 268.

¹⁵⁴ Suçun maddi unsurlarından birini oluşturan fiilin hareket ve neticeden meydana geldiğini kabul eden yazarlar, neticesi olmayan bir suçtan söz edilemeyeceği görüşündedir. Bu yazarlara göre, örneğin hakaret veya iftira gibi suçlar “neticesi harekete bitişik suçlar” niteliğindedir. Keza, 765 s. TCK'nın bir “gerçek ihmali suç” niteliğinde tanımlanan 230. maddesindeki görevi ihmal suçu da “neticesi harekete bitişik bir suç” olarak kabul edilmektedir.

Bir suçla ilgili olarak her halde bir neticeden söz edildiğine göre, gerçekleştirilen hareketle netice arasında illiyet bağının olması da bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştı. Bu yazarlara göre, “gerçek ihmali suçlar”da da hareketle netice arasında bir illiyet bağı mevcuttur (DÖNMEZER/ERMAN I, sh. 473; HAKERİ, Genel Hükümler 14. bası, sh. 181; aynı yazar: *Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmali Suçların Çeşitleri*, Ankara, Şubat 2003, sh. 234 vd.; aynı yazar: *Kasten Öldürme Suçları*, Ankara, Ocak 2006, sh. 156 vd.). Ancak bu suçlarda illiyet bağının tespiti bir sorun oluşturmamaktadır (KUNTER, Suçun Maddi Unsurları, sh. 208).

Başka bir deyişle, burada söz konusu edilen netice, sadece kanunî tarifte yer alan dış alemdeki değişikliktir¹⁵⁵. Meselâ, kasten öldürme suçunda (m. 81) bir insanın ölmesi, suçun maddi unsurlarından biri olan netice unsurunu oluşturmaktadır.

Çoğu suçlar açısından fiilin icra edilmesiyle suç tamamlanmaktadır. Meselâ, hakaret suçunda (m. 125), bir insanın şerefine tecavüz oluşturan söz ve davranışların icra edilmesiyle¹⁵⁶; iftira suçunda (m. 267), suçsuz olan bir kişiye suç takibe yetkili makamlar nezdinde suç isnadında bulunulmasıyla, suç tamamlanmış olmaktadır. Bu suçlara doktrinde “*sırf hareket suçları*” denmektedir^{157, 158}.

Buna karşılık, bazı suçlarda, salt fiilin icra edilmesinden ayrı olarak kanunî tarifte belirtilen neticenin meydana gelmesi gerekir ki suç tamamlanmış olsun¹⁵⁹. Meselâ, kasten öldürme suçunda (m. 81), öldürmeye matuf fiilin yanı sıra, bir insanın ölmesi halinde suç tamamlanmış olmaktadır. Mala zarar verme suçunda (m. 151), malvarlığına zarar vermeye matuf fiilin işlenmesinin yanı sıra, suçun tamamlanması için eşya üzerinde zarar neticesinin de doğması gerekmektedir. Keza, hırsızlık (m. 141 vd.), dolandırıcılık (m. 157) ve yağma (m. 148) suçlarının tamamlanabilmesi için, malikin veya meşru zilyedin suçun konusunu oluşturan malvarlığı değeri üzerindeki zilyedliğinin sona erdirilmesi ve bu malvarlığı değeri üzerinde failin zilyetlik tesis etmesi gerekir. Doktrinde bu suçlara “*neticeli suçlar*” denmektedir¹⁶⁰.

III. Nedensellik (İllyet) Bağlantısı

Kanunî tarifte fiilin icrasının yanı sıra, bir neticenin gerçekleşmesinin yer verildiği suçlarda, bu netice ile icra edilen fiil arasında nedensellik bağının bulunma-

¹⁵⁵ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 2. bası, sh.66/67.

¹⁵⁶ Bazı yazarlar örneğin hakaret ve iftira suçlarında da bir neticenin varlığını kabul etmektedirler (Bkz. HAKERİ, Ceza Hukuku, 18. bası, sh. 177 vd.).

¹⁵⁷ Doktrinde bu suçlara “*neticesi harekete bitişik suçlar*” da denmektedir. Bu anlayış, her suçta mutlaka bir netice olduğu düşüncesine dayanmaktadır: DÖNMEZER/ERMAN I, no. 516, 611; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, sh.67; TOROSLU, Ceza Hukuku(4), sh. 54; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 55; DARA-GENLİ, Vesile Sonay: *Tehlike Suçları*, in: Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul, 1999, sh. 178.

¹⁵⁸ Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar esas itibarıyla bir hareket suçudur. Bu suçların oluşabilmesi için, cinsel davranışın mağdur üzerinde bir netice meydana getirmesi gerekmez. Cinsel davranışa bağlı olarak mağdurun vücudu üzerinde bir neticenin meydana gelmesi, bu suçlar bakımından bir neticesi sebebiyle ağırlaşmış hal olarak değerlendirilmek gerekir. Bu açıklamalardan, cinsel dokunulmazlığa karşı suçların bir zarar suçu değil, tehlike suçu olduğu sonucu çıkarılamaz.

¹⁵⁹ KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler (6), sh. 72.

¹⁶⁰ DÖNMEZER/ERMAN I, no. 516; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/ MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, sh.67; TOROSLU, Ceza Hukuku(4), sh. 55.

sı gerekir. Nedensellik bağlantısı, **fail ve icra ettiği fiil ile gerçekleşen netice arasındaki objektif ilişkiyi** tesis etmektedir. İcra edilen fiil ile gerçekleşen netice arasında illiyet bağının mevcudiyeti sorumluluk için şarttır. Başka bir deyişle, gerçekleşen netice failin fiilinin eseri değilse, sorumlulukla ilgili bir tartışmaya gerek yoktur.

Failin fiili ile gerçekleşen netice arasındaki sebep – sonuç ilişkisini ifade eden illiyet bağı, tamamen **doğal bir olgudur**, tabii bir vakiydir, fenomendir.

Dolayısıyla, 19. yüzyıl ceza hukuku anlayışının devamı olan illiyet bağlantısının hukuki bir fenomen olduğu hususundaki görüşler¹⁶¹, isabetli değildir.

Bu kapsamda ileri sürülen bir görüş, neticenin oluşumu üzerinde etkili olan bütün davranışları eşdeğerde kabul etmekteydi (*eşdeğerlilik teorisi*)¹⁶². Dolayısıyla, bütün bu davranışları gerçekleştiren kişiler, sorumluluk açısından eşit bir muameleye tabi tutulmaktaydılar. Meselâ, bir suçun birden fazla kişinin iştirakiyle işlenmesi durumunda, suçun işlenişine bulunduğu katkının mahiyeti ne olursa olsun, bütün suç ortakları aralarında herhangi bir ayırımı gözetilmeksizin fail olarak sorumlu tutulmaktaydılar. Buna göre, mağduru hedef alarak silahı ateşleyen kişi ile, mermi veya silahı temin eden kişi aynı cezaya mahkûm ediliyordu¹⁶³.

Buna karşılık, neticenin oluşumuna sebebiyet veren fiilleri eşdeğerde kabul etmeyen görüşlerin birinci ortak noktası, bu fiilleri neticenin oluşumu üzerindeki etkileri itibarıyla ayırma tabi tutmaktaydı. Birbirinden çeşitli yönleriyle farklılıklar arzeden bu görüşler ceza hukukunda sorumluluğun esasını illiyet bağıyla açıklamaya çalışmaktaydı. Meselâ, neticenin oluşumuna sebebiyet veren davranışlar, bu oluşum üzerindeki etkisine göre “sebebe” veya “vesile” diye ikiye ayrılmışlardı¹⁶⁴. Buna göre, neticenin oluşumu üzerinde doğrudan etkili olan davranışlar, “sebebe”; neticenin oluşumu üzerinde dolaylı bir şekilde etkili olan davranışlar ise, “vesile” olarak nitelendirilmekteydiler. Teşebbüs söz konusu oldu-

¹⁶¹ EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 281. İlliyet bağına hukuki bir fenomen olarak kabul eden görüşler, somut olaydaki sorumluluğun izahında hep bu bağın kurulmasını esas almaktadırlar. Meselâ, yaralandığı için hastaneye kaldırılan kişi hastanede çıkan bir yangın sonucu ölmüş olsa, yaralayan kişinin bu ölüm neticesinden sorumlu tutulup tutulmayacağı illiyet bağıyla açıklanmaya çalışılmıştır (EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 277, 279).

¹⁶² “Äquivalenztheorie”

¹⁶³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 41 vd.

¹⁶⁴ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 442; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 277; DÖNMEZER/ERMAN I, no. 634. Bu anlayışın etkisindeki *Hafizoğulları*, yeni TCK’nın 22. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.” hükmünü eleştirirken, madde metninde veya gerekçesinde, taksirli suçun birden fazla kişinin katılımıyla işlenmesi hâline özgü “en önemli mesele olan *fiillerin neticeye nedensel katkılarının* her bir failin kusurunun takdirinde göz önüne alınıp alınmayacağı” hususunda açıklık bulunmamasını bir “eksiklik” olarak telakki etmektedir (HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 253).

ğunda, “sebebe” teşkil eden davranışlar icra hareketi; “vesile” teşkil eden davranışlar ise, hazırlık hareketi olarak nitelendirilmişlerdi. Buna karşılık, iştirakte, “sebebe” teşkil eden davranışlar “asli fail”, “vesile” teşkil eden davranışlar “fer’î fail” olarak sorumlu olmayı gerektirmekteydi¹⁶⁵.

Gerçekleştirilen fiilin kanunî tarifte belirtilen neticenin oluşumu açısından illî etkisinin olup olmadığının belirlenmesinde, çeşitli teorik mülahazalar ileri sürülmüştür. Ancak, bütün bu görüşler bugün için sadece tarihî bir kıymet taşımaktadır¹⁶⁶. Ülkemiz uygulamasında etkisini devam ettirdiği için, bu görüşlerden “*uygun illiyet teorisi*” ve bunun bir türevi olan “*karma uygunluk teorisi*” üzerinde kısa bir açıklamada bulunmak gerekir.

Uygun illiyet teorisi, suçun icrası cümlesinden olarak gerçekleştirilen hareketler arasında bir ayırım yapmaktadır. Bu ayırimda başvuru yegane ölçüt, gerçekleştirilen hareketin neticeyi meydana getirmeye elverişli olup olmadığıdır.

Ancak, bu elverişliliğin belirlenmesinde de bir ölçüte ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ölçütün de ne olacağı önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Elverişlilikle ilgili bu değerlendirme, ex ante mi yoksa ex post mu yapılacaktır; bu değerlendirmede fail mi, yoksa üçüncü bir kişi mi esas alınacaktır?

Uygun illiyet teorisini esas alan “karma uygunluk teorisi”ne göre; icra edilen hareketin neticenin oluşumuna etkili olup olmadığı, normal ve olağan hayat şartları itibarıyla yapılacak bir değerlendirmeye tespit edilecektir. Bu belirlemede, hükmü verecek olan kişi, genellikle kendi bilgisine ve hayat tecrübelerine göre karar vermektedir. Fakat, bu değerlendirmenin daha sağlıklı olabilmesi için, somut olayda fail açısından da ayrıca bir araştırmanın yapılması gerekmektedir.

Buna göre, objektif açıdan yapılan değerlendirmede, hareketin yapıldığı koşullara gidilir ve o andaki somut koşullar üçüncü kişinin bilgi ve tecrübesine göre irdelenerek gerçekleşen hareketin söz konusu neticeyi oluşturmaya uygun olup olmadığı belirlenir (objektif değerlendirme). Daha sonra ise, fail gözönünde bulundurularak sübjektif bakımdan bir değerlendirmeye gidilir. Yani, somut olayda meydana gelen neticeyi tahmin edebilme açısından failin kişisel bilgi ve tecrübesi araştırılır (sübjektif değerlendirme).

Bu objektif ve sübjektif değerlendirmeler birbirleriyle uyum arz ediyorsa, hem nedensellik bağlantısının hem de *kusurluluğun* mevcut olduğu sonucuna ulaşılacaktır.

Bu değerlendirmelerin birbiriyle çelişmesi durumunda ise, şöyle bir yol izlenmektedir:

Şayet objektif olarak öngörülme neticeyi fail öngörmüş ve netice gerçekleşmiş ise, artık illiyet bağlantısının varlığı kabul edilecektir.

¹⁶⁵ Bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 45, 46.

¹⁶⁶ Bu görüşlerle ilgili bilgi için bkz. DÖNMEZER/ERMAN I, no. 626 vd.

Buna karşılık, objektif olarak öngörülebilir olan neticeyi fail öngörmemişse, içinde bulunduğu şartlar itibarıyla bu neticenin fail tarafından öngörülmesinin mümkün olup olmadığı araştırılmaktadır. Şayet içinde bulunduğu şartlar itibarıyla gerçekleşen neticeyi öngörmesi failden beklenemeyecek ise, bu durumda illiyet bağlantısının gerçekleşmediği sonucuna ulaşılmaktadır¹⁶⁷.

Dikkat edilmelidir ki, bu görüş, aslında kusur konusunu ilgilendiren meseleleri illiyet bağlantısı kapsamında çözümlemeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım, suç teorisine ilişkin pek çok meselenin açıklanmasında illiyet bağlantısını esas alan 19. yüzyıl ceza hukuku düşüncesinin bir tezahürüdür.

İllyet bağlantısıyla ilgili olarak TCK kapsamında genel bir hüküm bulunmamaktadır. **Tamamen doğal bir olgu olan illiyet bağlantısı**yla ilgili olarak Kanunda genel bir hükme yer verilmemesi, bir eksiklik değildir; aksine, doğru olan bir tercihtir. Bu düşüncenin etkisiyledir ki, mülga 765 s. TCK'daki 451. madde hükmüne yeni TCK'da yer verilmemiştir¹⁶⁸.

¹⁶⁷ DÖNMEZER/ERMAN I, no. 658 vd.; İÇEL, Taksir sh. 169 vd.; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 76 vd. Ayrıca bkz. ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 106 vd.

¹⁶⁸ Söz konusu 451. madde hükmü şöyledir:

“Ölüm, failin fiilinden evvel mevcut olup da, failce bilinmeyen ahvalin birleşmesi veyahut failin idaresinden hariç ve gayri malhuz esbabın inzimamı yüzünden vukua gelmiş ise; idam cezasını müstelzim hallerde, on beş seneden; ve müebbet ve on beş seneden fazla ağır hapsi müstelzim hallerde, on seneden aşağı olmamak üzere, ağır hapis cezası hüküm olunur.”

451. maddedeki hükmün özelliği, fail **öldürme kastıyla** hareket etmekle beraber, **ölüm neticesi failin fiilinin yanı sıra**, bu fiilden **başka bir sebebin de etkisiyle meydana gelmektedir**. Ancak, neticenin oluşumu üzerinde etkili olan bu başka sebebin *failin bilgisi ve iradesi dışında* gerçekleşmiş olması gerekir.

Maddedeki düzenleme biçimine göre; bu başka sebep, failin fiilinden *önce* meselâ mağdurda mevcut olan bir hastalık olabilir. Mağdur hemofili hastasıdır, kanı pıhtılaşmamaktadır; basit bir yaralama sonucunda kan kaybından ölebilir. Ya da, mağdur kalp hastasıdır; kendisini strese sokacak bir davranışta bulunmak, ölümü için yeterli olabilir.

Mağdurun ölümü, fail fiili icra ettikten sonra ortaya çıkan başka bir sebebin eklenmesi sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Meselâ, fail, mağduru öldürmek kastıyla yaralamıştır; kişi ölmemiştir; kurtarılacak ve tedavi edilmek için başkaları tarafından hastaneye götürülürken yolda bir trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazada mağdur ölmüştür. Ya da, hastaneye kaldırılan yaralı mağdur, hastanede gerekli tıbbi müdahalede bulunulmakta gecikilmesi veya tıbbi müdahalenin icab ettirdiği tarz ve mahiyetin dışında bir muameleye maruz kalması dolayısıyla ölmüştür.

Bu gibi durumlarda Kanun, kasten adam öldürme suçuna ilişkin cezalarda indirim yapılmak suretiyle failin cezalandırılmasını emretmektedir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu başka sebep eğer önceden mevcut ise, fail bunun varlığını *bilmeyecektir*. Sonradan eklenen bir sebep ise; bu sebep, fail açısından *gayrimelhuz* (mülâhaza edilmemiş, öngörülmemiş) ve dolayısıyla, irade edilmemiş olmalıdır.

Bu itibarla, eğer, meselâ fail hemofili hastası olduğunu bildiği bir kişiyi öldürmek amacıyla vücudunun hayati tehlike arzermeyen bir bölgesine bıçak saplasa ve mağdur kan kaybı sonucunda ölse; bu fiil, somut olayda ölüm neticesini meydana getirmeye elverişlidir ve fail, bu

durumda kasten adam öldürme suçundan (448, 449 veya 450. madde hükümlerine göre) cezalandırılmak gerekir.

451. madde açısından mesele teşkil eden husus, failin gerçekleştirdiği fiilin başlı başına ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli olup olmamasıdır.

Yargıtay, çeşitli kararlarında 451. madde hükmünün uygulanabilmesi için failin gerçekleştirdiği fiilin başlı başına ölüm neticesini meydana getirmeye *elverişli olmaması* gerektiğini ileri sürmüştü:

«... Koyunların (verdiği zarar dolayısıyla aralarında) çıkan tartışmada M, S'ye sövm(üş) ve tokat atm(ıştır). Bunun üzerine S, tabancası ile ateş ederek M'yi akciğer, karaciğer, diyafram ve bağırsakları tahrip edecek şekilde sağ meme nahiyesinden yaralamak suretiyle kasten öldür(müştür). Ölüm bu yaraların tevhit ettiği peritonitten ileri gelmiş ve kurşunun vücutta bir çok organlarda husule getirdiği tahribat bizatihi öldürücü olmasına nazaran; ameliyatta kolundaki bir deliğin dikilmemesi, inzimam eden sebep sayılam(az. Çünkü) 451'nci maddenin uygulanabilmesi için ika edilen yaranın bizatihi öldürücü olmaması, ancak inzimam eden sebep yüzünden ölümün meydana gelmesi gerekir.»: 1. CD, 28.1.1976, 3624/289 (YKD, Haziran 1976, sh.907 vd.).

Bu görüşe göre, gerçekleştirdiği fiil başlı başına ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli olması halinde, failin tamamlanmış kasten adam öldürme suçundan dolayı cezalandırılması gerekmektedir.

«Olay gecesi sanık Nazmiye ile vaki ilişkisi sebebiyle evlerine girmiş olan maktûlü av tüfeği ile lomber bölgesinden dalağını tahrip edecek şekilde yaralamak suretiyle öldüren sanık Ramazan hakkında 451. maddenin uygulanabilmesi için *ika edilen yaranın bizatihi öldürücü olmaması gerekir*. Olayımızda ise yara bizatihi öldürücü niteliktedir. Zamanında ve erken müdahale edilmemesi gayri melhuz sebep değil, melhuz bir sebeptir. Hiçbir sanık yaraladığı kimsenin erken ve zamanında tıbbi müdahaleye mazhar olmasını bekleyemez. Aksi halde dağ başlarında tıbbi müdahalede bulunma imkânı olmayan yerlerde vukua gelen olaylarda tıbbi müdahaleye mazhar olmadan ölenlerle, geç mazhar olunan tıbbi imkâna rağmen ölenler arasında sanıkların sorumluluğu bakımından bir eşitsizliğe cevaz verilmiş olur ki bu tamamen yasa dışı bir uygulama olur. Bütün bu sebepler muvacehesinde, ... yaralanan maktûlün zamanında tıbbi müdahale yapılmaması yüzünden ölmesi hali(nin), inzimam eden gayri melhuz bir sebep sayılmaması gerektiği halde; Adli Tıp Meclisinin yasaya aykırı, ihtimale dayanan mütalâasına dayanılarak, sanık hakkında 451. maddenin uygulanması» doğru değildir: 1. CD, 5.5.1976, 1658/1672 (YKD, Eylül 1976, sh.1371 vd.).

İfade edelim ki; Yargıtay'ın bu görüşüne katılmamız mümkün değildir. **Eğer failin gerçekleştirdiği fiil başlı başına ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli değilse**, bu fiilin işlenmesinin yanısıra meselâ mağdurun kalp hastası, hemofili hastası olması gibi failce bilinmeyen başka bir sebebin etkisiyle ölüm gerçekleşmiş ise, **faili kasten adam öldürme suçundan sorumlu tutmamız mümkün değildir**. Çünkü, kanunî tarifinde ayrıca bir neticeye yer verilen suçlarda, **icra hareketinden söz edebilmek için gerçekleştirilen fiilin neticeyi meydana getirmeye elverişli olması gerekmektedir**.

Bu itibarla, Ceza Kanunu bünyesinde böyle bir hükme yer verilmesinin gereksiz ve hatta, isabetsiz olduğu düşüncesindeyiz. (ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 115 vd.). Ancak, işaret edelim ki, söz konusu 451. madde hükmü, dili sadeleştirilmek ve ceza indirim oranlarında değişiklik yapılmak suretiyle yeni TCK'na ilişkin Hükümet Tasarısına sistem olarak aynen alınmıştı (m. 137):

«Ölüm, fiilden evvel var olup da failce bilinmeyen hallerin birleşmesi veya failin iradesi dışında ve beklenilmeyen sebeplerin eklenmesiyle meydana gelmiş ise:

- 1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren hallerde onaltı yıldan yirmi yıla kadar,
- 2) Müebbet ve onbeş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren hallerde onbir yıldan onbeş yıla kadar, hapis cezası hükmolunur.”.

Bazı durumlarda sonradan gerçekleştirilen fiil, önceden gerçekleştirilen fiilin meydana gelen netice üzerinde etki doğurmasını engelleyebilir. Meselâ, A, C'yi öldürmek amacıyla yemeğine zehir katar. C yemeği yer ve fakat, zehir C'nin ölümünü sonuçlamadan B, C'ye silahla ateş eder ve aldığı yaraların etkisiyle C ölür. Burada A'nın fiili ölüm neticesini meydana getirmeden B'nin fiili gerçekleşir ve C, sonradan gerçekleşen bu fiilin etkisiyle ölür. Bu nedenle, C'nin ölümü bakımından B'nin fiili yeni bir illiyet bağı ortaya çıkarmıştır.

Bu durumda A, kasten öldürme suçunun icra hareketlerini gerçekleştirmiş ve fakat, bu hareketler, ölüm neticesini gerçekleştirmemiştir. Bu nedenle, A'nın fiili **kasten öldürme suçuna** (TCK, m. 81) **teşebbüs** aşamasında kalmıştır. Buna karşılık, B, **tamamlanmış kasten öldürme suçundan** sorumlu tutulacaktır.

Dikkat edilmelidir ki, bu örnek olayda A'nın fiili ile C'nin ölümü arasında artık nedensellik bağı bulunmamaktadır.

Ancak bazı durumlarda örneğin ölüm neticesi başka bir sebebin etkisiyle meydana gelmiş olsa bile failin fiil ile bu netice arasında nedensellik bağı varlığını muhafaza eder. Bu gibi durumlarda failin fiili ile netice arasındaki illiyet bağı varlığını muhafaza etmesine rağmen, neticenin oluşumunda bir başka sebep de etkili olduğu için, bu neticenin faile **objektif** olarak **isnadiyeti** mümkün olmaktadır. Tek başına fiil ile netice arasında nedensellik bağının varlığı, failin bu neticeden sorumluluğu için yeterli değildir. Nedensellik bağının yanı sıra, meydana gelen neticenin faile objektif olarak isnat edilebilir nitelikte olup olmadığı hususunda bir **hukuki değerlendirmeye** ihtiyaç bulunmaktadır.¹⁶⁹

Bu bağlamda şu örnekler verilebilir:

1. Örnek Olay: Avdan dönen A, tüfeği ile köy kahvesine girer, kahvede bulunan diğer şahıslar arasındaki tartışmayı duymasına rağmen, tüfeği bir kenara kor

Yukarıda açıkladığımız mülahazalarla yeni TCK'nın sisteminde böyle bir hükme yer verilmesine gerek görülmemiştir. Eğer failin gerçekleştirdiği fiil, ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli değilse, fail tarafından bilinmeyen başka bir sebebin etkisiyle ölüm neticesinin meydana gelmiş olması halinde, artık kasten öldürme suçundan dolayı cezaya hükmetmek imkânımız bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda şayet şartları varsa **taksirle ölüme sebebiyet vermek** suçundan (TCK, m. 85) dolayı cezaya hükmetmek yoluna gidilebilir.

Buna karşılık, şayet **failin gerçekleştirdiği fiil**, başlı başına **ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli ise**, bu neticenin meydana gelmesinde fail tarafından bilinen veya bilinmeyen başka bir sebebin etkili olması, kişinin **tamamlanmış kasten öldürme suçundan dolayı cezalandırılmasına engel teşkil etmeyecektir**. Nitekim, Yargıtay da söz konusu "elverişsizlik" kıstasıyla, belirtilen durumlarda bu madde hükmünün uygulanmasının yolunu kapamıştı.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki, somut olayda, failin **öldürme kastıyla** hareket ettiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yani failin öldürme kastıyla değil de **yaralama kastıyla** hareket etmesi halinde, olayları **kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış hali** (TCK, m. 87, f. 4) olarak değerlendirmek gerekmektedir.

¹⁶⁹ Bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler (6), sh. 130 vd.

ve olayları seyreder. Kızıışan tartışma sonucunda çıkan kavgada B, A'nın tüfeğini kapar ve C'yi öldürür.

Bu olayda B, kasten öldürme suçunu işlemiştir. A'nın dikkatsiz ve özensiz davranışıyla, C'nin ölümü arasında nedensellik bağı vardır. Ancak, A'yı ne B'nin işlediği kasten öldürme suçuna iştirakten ne de taksirle ölüme sebebiyet vermektan dolayı sorumlu tutabiliriz. Çünkü B'nin bilahare gerçekleştirdiği kasıtlı fiil, C'nin ölümünün A'ya objektif olarak isnadiyetini engeller¹⁷⁰.

2. Örnek Olay: Dikkatsiz ve özensiz araç kullanan A, bir trafik kazasında C'nin yaralanmasına sebebiyet verir. Yaralanan C, B'nin kullandığı araçla tedavi için hastaneye kaldırılır. B'nin hızlı araç kullanması ve trafik işaretlerine riayet etmemesi sebebiyle oluşan ikinci trafik kazasında C, ölür.

Dikkat edilmelidir ki, A'nın dikkatsiz ve özensiz davranışı ile C'nin ölümü arasında nedensellik bağı vardır. Ancak, sadece nedensellik bağının varlığı failin bu neticeden sorumlu tutulabilmesi için yeterli değildir. Ayrıca, bu neticenin, faile objektif olarak isnat edilebilmesi gerekir. Bu itibarla, B'nin dikkatsiz ve özensiz araç kullanması sebebiyle oluşan trafik kazasında C'nin ölmüş olmasından, A'yı ceza hukuku bakımından sorumlu tutmamak gerekir. Bu olayda A'nın taksirle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan (TCK, m. 89) dolayı, B'nin ise taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan (TCK, m. 85) dolayı cezalandırılması gerekmektedir.

3. Örnek Olay: Dikkatsiz ve özensiz araç kullanan A, bir trafik kazasında B'nin yaralanmasına sebebiyet verir. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. B, hastanede kendisine uygulanan tedavide hata yapıldığı için ölür.

Bu örnek olayda A hakkında **taksirle yaralama suçundan** (TCK, m. 89) dolayı cezaya hükmetmek gerekir. Ayrıca, B'nin ölümüne dikkatsiz ve özensiz davranışlarıyla sebebiyet veren sağlık görevlileri hakkında, **taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan** (TCK, m. 85) dolayı cezaya hükmetmek gerekir^{171,172}.

¹⁷⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 186 vd.

¹⁷¹ Yargıtay, benzer olaylarda sorunu ilk hareketi gerçekleştiren kişinin fiili ile ölüm neticesi arasında illiyet bağının var olup olmaması olarak değerlendirmiştir:

«Oluş ile Adli Tıp 1. İhtisas Kurulunun raporu gözönüne alındığında; yaralıya hastaneye alındığında gerekli olan tetanos aşısı veya serumu yapılmış olsaydı ölüm meydana gelmeyeceğinden; yaralanmaya neden olan sanığın kusurlu davranışı ile ölüm arasında doğrudan doğruya *illiyet bağının varlığından söz edilemez*. Bu nedenle sanığın, iş ve güçten kalma süresine göre yaralanmaya sebebiyetten sorumlu tutulabileceği düşünülmeden ölüme sebebiyetten mahkûmiyet hükmü tesisi bozmayı gerektirmiştir.»: 9. CD, 15.12.1987, 3887/5152 (Keskin, sh. 28).

Dikkat edilmelidir ki, bu olayda sorumluluk, sadece yaralanmaya sebebiyet veren kişi bakımından tartışılmıştır. **Olay, hastanede yanlış tedavi uygulayan sağlık görevlilerinin sorumluluğu ile ilgili olarak bir değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.**

¹⁷² Yargıtay **Ceza Genel Kurulu'nun 16.5.2017** tarihli ve E. 2017/12-271, K. 2017/278 sayılı kararına konu teşkil olayda; gündüz saat 11.25 sıralarında Enver, yönetimindeki kamyon ile

kavşak çıkışına geldiğinde, sağ tarafından karşıdan karşıya geçmek üzere yola giren 76 yaşındaki yaya Hakkı'ya çarpar. Hakkı, saat 12.30 sıralarında ... Devlet Hastanesinin acil servisine yaralı olarak getirilir. Nöbetçi olan pratisyen hekim Volkan tarafından Hakkı'ya müdahale edilip beş saat müşahede altında tutulduktan sonra saat 17.00 sıralarında taburcu edilir. Saat 17.48'de bilinci kapalı bir şekilde tekrar hastaneye getirilen Hakkı, yapılan müdahalelere rağmen ölür.

Volkan tarafından düzenlenen 72025 sayılı raporda, hastanın “*saat 12:48'de geldiği, genel durumu iyi, bilinç açık, oryante, koopere, yapılan FM'de; alın sağ kısmında 4x5 cm'lik ekimoz alanı mevcut, her iki diz üzerinde 2 cm'lik ekimoz mevcut, her iki el üzerinde 1 cm'lik ekimotik alanlar olduğu, hayati tehlikesi olmadığı, yaralanmanın basit müdahale ile ...; konuşma normal, duyu ve organlar normal, fraktür yok, geçici hekim raporu olduğu, kati raporun 24 saat sonra verileceği*” belirtilmiştir.

İkinci defa hastaneye getirilişi üzerine yine Volkan tarafından düzenlenen 72095 sayılı raporda, hastanın “*saat 17.45'de geldiği, GD. kötü, TA: 40/20, spontan solunumu mevcut, damar yolu açılarak sıvı takıldığı, entübe edildiği, TA alınamadığı, EKG'de atım kaybolduğu, elektrokardiyoversiyon yapıldığı, resüsitasyona devam edildiği, yanıt vermeyen hasta ex kabul edildiği*” belirtilmiştir.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen adli muayene ve otopsi tutanağında, Hakkı'nın kafa kemiğinde kırık olduğu, kaburgalarında kırıklar olduğu, bütün kırık bölgelerinde ekimozlu kanama tespit edildiği belirtilmiştir.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda, Hakkı'nın ölümünün trafik kazasına bağlı kaburga, kalça, kafatası, köprücük kemiği kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtilmiştir.

Hastaya hastanede röntgen filmleri çekilmiş ve hasta ile ilgili olarak sadece ilaç tedavisi uygulanmıştır.

Yüksek Sağlık Şurası raporunda, Volkan'ın “*multitравmalı hastaya yaklaşımda hatalı olduğu, kırıkları tespit edemediği, ağır travmaya rağmen hastayı sevk etmediği ve gerekli konsültasyonları yapmadan hastayı evine gönderdiği, hastanın durumunu multidisipliner değerlendiremediği ve tıbbın gereklerini yapmadığından kusurlu olduğu,*” değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 13.3.2013 tarihli ikinci raporda, “*kırıkların tespit edilmemesinin eksiklik olduğu, ancak kişide tespit edilen travmatik değişimlerin ağırlıkları ve kişinin yaşı da dikkate alındığında zamanında tespit edilerek uygun tedavisinin başlanması durumunda da kişinin kurtulmasının kesin olmadığı,*” değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu olayda, doktor Volkan bakımından aşağıdaki gerekçe ile taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun (TCK, m. 85, f. 1) değil, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun (TCK, m. 257, f. 2) oluştuğu yönünde içtihatla bulunmuştur:

“... sanığın davranışları ile meydana gelen ölüm neticesi arasında nedensellik bağının kesin olarak belirlenemediği, bu nedenle sanığın meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulamayacağı, bununla birlikte ... sanığın, genel beden travmasına ve çoklu kemik kırıklarına maruz kalmış öleni stabilizasyonu sağlanıncaya kadar ve tıp çevrelerinde genel olarak kabul gördüğü şekilde yirmidört saat müşahede altında tutması veya başka bir sağlık kuruluşuna sevk etmesi gerekirken, beş saat sonunda taburcu ederek evine göndermesi suretiyle görevinin gereklerini yerine getirmekte ihmal gösterdiği, bu haliyle eyleminin TCK'nın 257/2. maddesinde düzenlenen görevi ihmal suçunu oluşturduğu ve bu suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın eyleminin taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçu kabul edilerek TCK'nın 85/1. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.”

4. Örnek Olay: Dikkatsiz ve özensiz araç kullanan A, bir trafik kazasında B'nin yaralanmasına sebebiyet verir. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. B, hastanede tedavi görürken, aldığı yaraların daha önce var olan hastalığını tetiklemesi sonucunda ölür.

Bu örnek olayda A hakkında **taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan** (TCK, m. 85) dolayı cezaya hükmetmek gerekir¹⁷³.

5. Örnek Olay: Dikkatsiz ve özensiz araç kullanan A, bir trafik kazasında B'nin yaralanmasına sebebiyet verir. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. B, kendisine uygulanmak istenen tedaviyi çeşitli sebeplerle kabul etmez; örneğin ken-

Hukuki değerlendirmemiz:

Söz konusu karar, hukuki bakımdan pek çok yönden sorunludur. Kararda, çeşitli kitaplara atıflarla bulunularak çeşitli ceza hukuku kavramlarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Ancak, çoğu yerde örneğin nedensellik bağlantısı ve objektif isnadiyet gibi kavramlar arasındaki ilişkide ve farklılıkta yanlış sonuçlara varılmıştır.

Karara konu teşkil eden olayda doktor Volkan'ın Hakkı'ya bulunduğu tıbbi müdahalenin pek çok yönden yanlış olduğu, kararda da belirtildiği üzere, ilgili otoriteler tarafından ortaya konulmuştur.

Volkan'ın bu yanlış tıbbi uygulamasının Hakkı'nın ölümü üzerinde etkisinin olmadığı söylenemez. Bu nedenle, olayda bir nedensellik bağı sorunu bulunmamaktadır. Karara konu teşkil eden olayda, birden fazla kişinin taksirli hareketinin sonucunda ölüm meydana gelmiş olduğu için, bu ölüm neticesi dolayısıyla, taksirli hareket eden her bir kişinin kendi taksirinden dolayı sorumlu tutulmasını gerektiren bir durum mevcuttur. Bu itibarla söz konusu olayı genel, tali ve tamamlayıcı suç olan (ihmalî davranışla işlenmiş) görevi kötüye kullanma suçu bağlamında değerlendirmeye tabi tutmak doğru olmamıştır.

Karara konu teşkil eden olayda Volkan'ın yükümlülüklerine aykırı davranışı kasten gerçekleştirdiğinden de söz edilemez. Oysa ister icraî ister ihmalî davranışla işlenmiş olsun, görevi kötüye kullanma suçu ancak kasten işlenebilir.

Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararında, taksirle ölüme sebebiyet verme suçu bakımından Volkan'ın fiili ile Hakkı'nın ölümü arasında "*nedensellik bağının kesin olarak belirlenmediği*" ifade edilirken, görevi kötüye kullanma suçu bakımından bu bağlantı kurulabilmiştir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen ikinci raporda yer verilen "*kırıkların ... zamanında tespit edilerek uygun tedavisinin başlanması durumunda da kişinin kurtulmasının kesin olmadığı*" şeklindeki değerlendirme, ceza hukuku sorumluluğunun belirlenmesi bağlamında hiçbir şekilde dikkate alınmamalıdır. Bu gerekçe, zaman zaman kişinin sorumluluktan kurtulmasını sağlamak için oluşturulmuş fiktif bir davanıdır. Tıbbi uygulama hatasına dayalı olarak gerçekleşen ölümlerde her zaman için bu gerekçeye dayanarak sorumluluktan kurtulmak mümkün olabilir.

¹⁷³ Yargıtay, benzer olaylarda sorunu illiyet bağının var olup olmaması olarak değerlendirmiştir:

«Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi 7.12.1988 tarihli mütalaasında ölenin trafik kazasına bağlı sağ kalça ve bacak kırığının daha önce kendinde mevcut olan şeker hastalığı ve böbrek hastalıklarının 2. ameliyat sonrası dönemde akut safhaya geçmesine yol açarak akut böbrek yetmezliği sonunda vefat ettiğini, ölüm ile geçirmiş olduğu kaza arasında dolaylı illiyet bağı bulunduğunu bildirmiş olmasına göre ölüm ile trafik kazası arasında doğrudan bir illiyet münasebeti olup olmadığı hususunda bir kere de Adli Tıp Genel Kurulundan görüş alınması; doğrudan illiyet bağı bulunmadığı ifade olunduğu takdirde sanığın yaralanmaya sebebiyet suçundan mahkûmiyeti cihetine gidilmesi gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar itihazi, bozmayı gerektirmiştir.»: 2. CD, 12.12.1989, 11490/12065 (Keskin, sh. 24).

disine kan verilmesi gerekirken, dini inancı sebebiyle kan verilmesini kabul etmez ve sonuçta ölür.

Bu durumda, A hakkında sadece **taksirle yaralama suçundan** (TCK, m. 89) dolayı cezaya hükmetmek gerekir.

6. Örnek Olay: Dikkatsiz ve özensiz araç kullanan A, bir trafik kazasında B'nin yaralanmasına sebebiyet verir. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. Hastanede B'ye gerekli tıbbi müdahalede bulunulur. B, hastanede bir süre tedavisine devam edildikten sonra, tedavi ile bağlantılı olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunulur ve belirli aralıklarla kontrole gelmek üzere evine gönderilir; ancak, tedavi ile bağlantılı olarak kendisine yapılan uyarıları dikkate almadığı için, yara enfeksiyon kapar ve sonuçta ölür.

5. örnek olayda olduğu gibi, bu durumda da, A hakkında sadece **taksirle yaralama suçundan** (TCK, m. 89) dolayı cezaya hükmetmek gerekir.

7. Örnek Olay: Dikkatsiz ve özensiz araç kullanan A, bir trafik kazasında B'nin yaralanmasına sebebiyet verir. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. B, hastanede çıkan yangında kurtarılamayarak ölür.

5. örnek olayda olduğu gibi, bu durumda da, A hakkında sadece **taksirle yaralama suçundan** (TCK, m. 89) dolayı cezaya hükmetmek gerekir.

8. Örnek Olay: A, öldürmek kastıyla B'ye ateş eder. B, A'nın silahından çıkan kurşunlardan isabet almamak için kaçır ve aniden yoldan geçmekte olan aracın önüne çıkar; aracın kendisine çarpması sonucunda ölür.

Bu gibi durumlarda **tamamlanmış kasten öldürme suçundan** dolayı cezaya hükmetmek gerekir¹⁷⁴.

¹⁷⁴ *Hakeri*, benzer durumlarda, A'nın *kasten öldürme suçuna teşebbüs*ten dolayı cezalandırılması gerektiği fikrindedir (HAKERİ, Hakan: *Kasten Öldürme Suçları*, 2. bası, Ankara, Eylül 2007, sh. 29).

Yargıtay ise, benzer olaylarda, 765 s. TCK'nın yürürlükte olduğu dönemde, 451. madde hükmünü uygulayarak, faile *kasten öldürme suçundan* dolayı verilen *cezada indirim yapılması* yoluna gitmekteydi. Bkz. 1. CD, 24.12.1996, 3864/4157.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22.03.2016 tarihli ve E. 2014/12-779, K. 2016/136 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, Ali Dursun ile Timur arasında gece geç saatlerde cadde kenarında tartışma çıkar. Bu tartışma dolayısıyla Ali Dursun elindeki ekmek bıçağı ile Timur'u kovalamaya başlar. Timur, kaçmaya çalışır ve bölünmüş caddenin orta refüjüne geçer. Ali Dursun'un kendisini kovalamaya devam etmesi üzerine, Timur, trafik durumunu dikkate almadan, yaklaşan vasıtaların uzaklık ve hızını dikkate almadan, orta refüjden caddenin karşısına geçmeye çalışır; ancak, aniden caddeye çıkması sebebiyle, sürücü Mehmet Ali'nin kullandığı aracın çarpması sonucu ölür.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince düzenlenen raporda; maktulün ölümüne neden olan trafik kazasının, yerleşim yerinde, 12,5 metre genişliğinde, refüjle bölünmüş, tek yönlü, eğimsiz, düz, kuru, asfalt kaplama yolda geceleyin meydana geldiği, havanın açık olduğu, otomobile ait çarpma noktası sonrası **35 metre sürüklenme** izinin tespit edildiği, araç sürücüsü Mehmet Ali'nin seyir hızını yerleşim yeri koşullarına göre ayarlamadığı; Timur'un tartıştığı kişi tarafından bıçakla kovalanması sırasında kontrolsüzce taşıt yoluna yöneldiği; Ali Dur-

sun'un ise yol kenarında tartıştığı maktulü elinde bıçakla kovalayıp maktulün yola girmesine ve yol üzerinde yakın mesafede seyretmekte olan sürücünün aracı ile maktule çarpmasına sebebiyet verdiği tespitinde bulunulmuştur.

İlk derece mahkemesi bu olayda;

a) Ali Dursun hakkında, **kasten yaralama suçuna teşebbüsten** dolayı TCK, m. 86, f. 2; f. 3, bent e; m. 35 ... hükümleri uyarınca **4 ay 15 gün** hapis cezasına ve ayrıca, **taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme** suçundan dolayı TCK, m. 85, f. 1 ... hükümleri uyarınca **2 yıl** hapis cezasına hükmetmiştir.

b) araç sürücüsü Mehmet Ali hakkında **taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme** suçundan dolayı TCK, m. 85, f. 1 ... hükümleri uyarınca **1 yıl 8 ay** hapis cezasına hükmetmiş ve bu mahkumiyet hükmü ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermiştir (Ankara 19. Asliye CM, 25.07.2008, 697-929).

Ali Dursun'un mahkumiyeti yönünden söz konusu hükmün temyizi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonucunda, aşağıdaki gerekçe ile, Ali Dursun'un Timur'a karşı kasten silahla yaralama suçuna teşebbüsten ve taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dolayı ayrı ayrı değil, **olası kastla öldürme** suçundan dolayı sorumlu tutulması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur:

“Somut olayda sanık elinde öldürmeye veya yaralamaya elverişli bıçakla öleni kovalamış, akan trafiğe rağmen yola girerek saldırıdan kurtulmaya çalışan öleni takibini ısrarla sürdürmüş, yoldan geçen araçlardan yardım isteyen ölen hiç kimsenin kendine yardım etmemesinin verdiği çaresizlik ve saldırıdan kurtulmak amacıyla orta refüjden tekrar kaplamaya girmiş ancak, yolda seyir halinde bulunan bir aracın kendisine çarpmasıyla hayatını kaybetmiştir. Sanığın eylemi somut olayda öngörme hususu gerçekleştiğinden taksir boyutunu aşmıştır, sanık öngördüğü sonucun meydana gelmeyeceğine yönelik bir güvenle de hareket etmeyip, aksine muhtemel tüm sonuçları öngörmesine rağmen hareketini sürdürmüş dolayısıyla bu sonucu kabullenmiştir.” (Yargıtay 12. CD, 24.05.2012, 19124-14547).

Daire üyelerinden bir kısmı bu olayda Ali Dursun'un Timur'a karşı **bilinçli taksirle** ölüme sebebiyet verme suçundan dolayı mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gerekçesiyle, karşıoy kullanmışlardır.

Bozma kararına uyan ilk derece mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermiştir. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, Ali Dursun hakkında Timur'u **olası kastla öldürme** suçundan dolayı TCK, m. 81, f. 1; m. 21, f. 2 ... hükümleri uyarınca **16 yıl 8 ay** hapis cezasına hükmetmiştir (Ankara 5. Ağır CM, 21.03.2013, 430-90).

Re'sen temyiz incelemesine tabi olan bu mahkumiyet hükmü, Yargıtay 12. Ceza Dairesince onanmıştır (Yargıtay 12. CD, 14.05.2014, 9953-11705).

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “*sanığın eylemlerinin bilinçli taksir ile ölüme neden olma suçunu oluşturduğu*” gerekçesi ile, bu onama kararına itiraz etmiştir (09.07.2014, 153178).

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise, Ali Dursun'un Timur'a karşı fiilinin olası kastla öldürme suçunu değil, **bilinçli taksirle** ölümüne sebebiyet verme suçunu oluşturduğu gerekçesiyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, 12 Ceza Dairesinin onama kararının kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi hükmünün, sanığın eyleminin bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar vermiştir.

Ceza Genel Kurulunun bu kararına üyelerden bir kısmı karşı oy kullanmışlardır. Üyelerden biri karşı oy gerekçesinde;

Somut olayda, “meydana gelen kastedilenden başka ve ağır netice (ölüm) açısından sorumluluğun, kasta dayalı bir sorumluluk olduğu kuşkusuzdur.

Dolayısıyla kasta dayalı olarak gerçekleşen bıçakla kesintisiz kovalama eylemine (kasten yaralamaya teşebbüs ve taksirle ölüme sebebiyet şeklinde) iki farklı niteliğin yüklenmesi de kanunca mümkün değildir.

9. Örnek Olay: A, öldürmek kastıyla C'ye ateş eder; ancak, silahı bir atıştan sonra tutukluk yaptığı için atışlara devam edemez. Yaralanan C, B'nin kullan-

Eylemin bir bütün halinde olası kastla insan öldürme suçunu oluşturduğu"

görüşünü savunmuştur.

Hukuki değerlendirmelerimiz:

Bu tür olaylarda, öncelikle failin işlemeyi kastettiği suçu belirlememiz gerekmektedir. Failin hangi suçu işlemek kastıyla hareket ettiğini belirledikten sonra, sorumluluğunu buna göre tayin etmek gerekir.

Birinci ihtimal olarak olayda, Ali Dursun'un işlemeyi kastettiği suç, **kasten yaralama** suçudur. Bu suçun işlenmesi için, elinde bulundurduğu bıçak, **silah** olarak söz konusu suçun nitelikli unsurudur.

Ancak, Ali Dursun, yaralama suçunun **icrasına henüz başlamış değildir**. Çünkü Kanun "**doğrudan icraya başlama**"dan söz etmektedir. Bu nedenle, söz konusu olayda Ali Dursun, **kasten yaralama suçuna teşebbüsten dolayı sorumlu tutulamaz**. Bu durumda, Ali Dursun'un işlediği fiil tehdit, hakaret gibi başka bir suçu veya suçları oluşturduğu takdirde, ancak bu suç veya suçlar sebebiyle cezalandırılması yoluna gidilebilir.

Şayet Ali Dursun, elindeki bıçağı Timur'a doğru savurmasına rağmen, kaçtığı için Timur'a isabet ettirememiş olsaydı suçun icrasına başladığı için, Ali Dursun'u **kasten yaralama suçuna teşebbüsten dolayı sorumlu tutmak** gerekirdi.

Ancak Timur, korkarak kaçmaya çalışırken, önüne düştüğü seyir halindeki aracın çarpması sonucu ölür. Bu durumda Timur'un ölümünden Ali Dursun'u sorumlu tutmak gerekir. Ali Dursun'un icra ettiği fiil ile Timur'un ölümü arasında **nedensellik bağı mevcuttur**. Ancak, bu durumda Ali Dursun'u sadece (bilinçli veya bilinçsiz) **taksirle ölüme sebebiyet verme** suçundan dolayı sorumlu tutmak gerekir.

Bu olayda Ali Dursun'un işlediği fiil, **kasten öldürme suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halini oluşturmaz**. Çünkü, kasten öldürme suçunun icrasına henüz başlanmış değildir.

Bir an için varsayım olarak, Ali Dursun'un kovalama fiili ile kasten yaralama suçunun icra hareketlerinin başladığı kabul edilse bile, bu kabul karşısında da, olayda kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinden söz edilemez. Çünkü, **neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinden söz edebilmek için, kasten yaralama suçunun tamamlanmış olması gerekmektedir**.

Bu durumda da Ali Dursun'u sadece (bilinçli veya bilinçsiz) **taksirle ölüme sebebiyet verme** suçundan dolayı sorumlu tutmak gerekir.

İkinci ihtimalde ise, olayda, Ali Dursun'un işlemeyi kastettiği suç, **kasten öldürme** suçudur. Timur, şayet kaçmakla kurtulmuş olsaydı, Ali Dursun kasten öldürme suçuna teşebbüsten dolayı sorumlu tutulamazdı. Çünkü suçun icrasına henüz başlanmış değildir.

Şayet Ali Dursun'un, elindeki bıçağı bir veya birkaç kez savurmasına rağmen, Timur kaçarak yara almadan kurtulmuş olsaydı; kasten öldürme suçunun icrasına başladığı için, Ali Dursun'u **kasten öldürme suçuna teşebbüsten dolayı sorumlu tutmak** gerekirdi. Ancak söz konusu olayda Ali Dursun, kasten öldürme suçunun doğrudan icrasına henüz başlanmış değildir.

Ancak, Ali Dursun'un **öldürmeyi** kastettiği ve bu **kasıtlı** elinde bıçakla kovaladığı Timur, korkarak kaçmaya çalışırken, önüne düştüğü seyir halindeki aracın çarpması sonucu ölür. Bu durumda Timur'un ölümünden Ali Dursun'u sorumlu tutmak gerekir. Ali Dursun, Timur'u bıçakla yaralayarak öldürmek isterken, Timur, önüne düştüğü seyir halindeki aracın çarpması sonucunda ölür. Ali Dursun'un kovalama fiili ile Timur'un ölümü arasında **nedensellik bağı mevcuttur**. Bu durumda Ali Dursun'u, birinci ihtimalden farklı olarak, **kasten öldürme** suçundan dolayı sorumlu tutmak gerekir.

dığı araçla tedavi için hastaneye kaldırılır. B'nin hızlı araç kullanması ve trafik işaretlerine riayet etmemesi sebebiyle oluşan trafik kazasında C, ölür.

Bu olayda da, A'nın kasıtlı fiili ile C'nin ölümü arasında nedensellik bağı vardır. Ancak, burada da objektif isnadiyet¹⁷⁵ prensibinden hareketle, B'nin dikkatsiz ve özensiz araç kullanması sebebiyle oluşan trafik kazasında C'nin ölmüş olmasından, A'yı ceza hukuku bakımından sorumlu tutmamak gerekir. Bu olayda A'nın **kasten öldürme suçuna** (TCK, m. 81) **teşebbüsten** dolayı, B'nin ise, **taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan** (TCK, m. 85) dolayı cezalandırılması gerekmektedir.

Ancak belirtelim ki, benzer bazı olaylarda, meydana gelen neticenin faile objektif olarak isnadiyeti mümkündür. Şöyle ki, örneğin A, uyuşturucu madde bağımlısı olan B'ye kullanması için fazla miktarda uyuşturucu madde satar. B, A'dan satın aldığı uyuşturucu maddeden yüksek dozda kullanır; sonuçta uyuşturucu komasına girer ve ölür. Bu tür olaylarda satıcı, satın alan kişinin uyuşturucu madde kullandığını ve hatta bağımlı olduğunu bilmekte ise, uyuşturucu madde kullanmaya bağlı olarak gerçekleşen ölüm neticesinden sorumlu tutulması gerekmektedir. Kanaatimizce, bu gibi durumlarda satıcı hakkında, **olası kastla** işlenmiş **kasten öldürme suçundan** dolayı cezaya hükmetmek gerekir¹⁷⁶.

Keza, örneğin A, otomobilini, sürücü belgesi olmayan B'ye verir. B, otomobille kaza yaparak C'nin ölümüne sebebiyet verir. Bu gibi olaylarda, A, sürücü belgesi olmadığını ve dolayısıyla, araç kullanma ehliyetinin bulunmadığını bilmesine rağmen, B'ye otomobilini teslim ederken, B'nin bir trafik kazasına sebebiyet verebileceğini ve bu kazada kişilerin yaralanabileceğini ve hatta ölebileceğini öngörmektedir. Buna rağmen, otomobilin B'ye vermiş olması nedeniyle C'nin ölümünden dolayı A'yı **olası kastla** işlenmiş **kasten öldürme suçundan** (TCK, m. 81, m. 21, f. 2) dolayı cezalandırmak gerekir. Ya da, B, otomobili teslim ederken A'nın kendisine yaptığı bütün uyarılara rağmen kazaya sebebiyet vermişse, bu durumda A'yı **bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek** suçundan (TCK, m. 89, m. 22, f. 3) dolayı sorumlu tutmak gerekir¹⁷⁷.

Belirtmemiz gerekir ki, bu açıklamalarımızla, uygun illiyet teorisi ile ilgili olarak yukarıda eleştirdiğimiz duruma kendimiz düşmüş değiliz. Bu örnek olaylarda, A'nın fiili ile meydana gelen ölüm neticesi arasında nedensellik bağı vardır.

¹⁷⁵ Objektif isnadiyet kavramı ile ilgili açıklamalar için bkz. ÇINAR, Ön Kusurluluk, sh. 52 vd.

¹⁷⁶ Ayrıca bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler (6), sh. 132.

¹⁷⁷ Ancak Yargıtay, benzer olaylarda sorunu illiyet bağının var olup olmaması olarak değerlendirmiştir:

«Dava konusu olay, araç sahibinin oğlu ölen K'nin aracı kusurlu sevk ve idaresinden doğmuş bulunmasına göre, aracın yönetimini bu şahsa tevdi eden sanığın fiili ile, sonuç arasında doğrudan doğruya bir illiyet rabıtası bulunmadığı gözetilmeksizin, araç sahibi sanık hakkında TCK'nın 455. maddesine istinaden mahkûmiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.»: 9. CD, 10.3.1983, 519/621 (Keskin, sh. 35).

Ancak, bazı yazarların, bazı durumlarda, illiyet bağının varlığına rağmen, meydana gelen neticenin objektif olarak A'ya isnat edilemeyeceği ve bu neticeden dolayı sorumlu tutulmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmaları dolayısıyla; bu açıklamaların tutarsızlığını ortaya koyabilmek için, suçun manevi unsuruyla bağlantılı açıklamalara da yer verme ihtiyacı hissetmiş bulunmaktayız.

10. Örnek Olay: A, öldürmek kastıyla B'ye ateş eder; ancak silahı bir atıştan sonra tutukluk yaptığı için atışlara devam edemez. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. B, hastanede kendisine uygulanan tedavide hata yapıldığı için ölür.

Bu olayda, 9. örnek olayla ilgili olarak oluşturduğumuz çözüm şeklinin izlenmesi gerekmektedir¹⁷⁸.

¹⁷⁸ AKBULUT, Genel Hükümler (5), sh. 354). Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2.6.2009 tarihli ve E. 2008/1-186, K. 2009/147 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; F, silahla ateş ederek M'yi iç organ ve bağırsaklarından yaralar. Hastaneye kaldırılan M, ameliyat edilir. Bu ameliyat sırasında M'ye yedi ünite kan verilir. Ameliyat sonrası bir süre daha tedavisine devam edilen M, iyileştikten bahisle hastaneden taburcu edilir. Ancak, M, bir süre sonra rahatsızlanarak tekrar hastaneye başvurur ve hastanede tedavisi devam ederken ölür.

Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunun Raporuna göre, silahla yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan M'ye ameliyat sırasında verilen kanla hepatit virüsü bulaşır. Bu Raporda, ölümün "akut hepatitten ileri geldiği" belirtilir.

Esas Mahkemesi, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen bu fiil dolayısıyla, F hakkında, **öldürme kastıyla** hareket ettiği için, mülga 765 s. TCK'nın 451. maddesi hükmüne istinaden sonuç itibarıyla 16 yıl 8 ay "ağır" hapis cezasına hükmeder.

Yargıtay 1.CD bu mahkumiyet hükmünü onar ve hüküm kesinleşir.

1 Haziran 2005 tarihinde yeni TCK yürürlüğe girdiği için Esas Mahkemesince uyarlama yargılaması yapılır. Bu yargılama sonucunda, F her ne kadar öldürmek kastıyla ateş etmiş ise de, ölüm neticesi sonradan ortaya çıkan başka bir sebep yüzünden gerçekleşmiştir. Bu nedenle, F'nin ancak **kasten öldürme suçuna teşebbüsten** dolayı cezalandırılması gerekir gerekçesiyle, 5237 s. TCK'nın 81 ve 35. maddeleri hükümlerine istinaden sonuç itibarıyla 13 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilir.

Bu hükmü de temyizen inceleyen Yargıtay 1.CD'ne göre; ölüm, ateşli silah yaralanmasının tedavisi için hepatit virüslü kan verilmesi sonucu gelişen akut hepatitten ileri gelmiştir. **Ateşli silah yaralanması ile ölüm arasında uygun nedensellik bağı mevcuttur.** Bu itibarla, olayda 5237 s. TCK'nın 81. maddesinde öngörülen **tamamlanmış kasten öldürme suçu** oluşmuştur. Mülga 765 s. TCK hükümlerine göre verilmiş olan mahkumiyet hükmünün failin lehine olduğu gerekçesiyle Esas Mahkemesinin uyarlama bağlamında kurduğu **hükmü bozar.**

Esas Mahkemesi, uyarlama bağlamında verdiği hükümde direnir. **Direnme kararında** şu gerekçelere yer verilir:

"... neticeye yönelik illi değer taşıyan hareketlerin başka bir hareketin birleşimi ile kesilmesi veya birleşmesi ve neticenin birinci veya ikinci hareketten hangisinin etkisi ile meydana geldiğinin ayırt edilememesi durumunda, birinci hareketin neticeyi meydana getirmeye elverişli olduğunu kabulle, doğrudan meydana gelen neticeden birinci hareketin sahibini sorumlu tutmaya yönelik bir uygulama adil olmayacaktır. Bu nedenle F'nin öldürme kastı taşıyan fiilinin neticeye doğrudan etkisinin olduğu, diğer bir anlatımla hepatitli kan verilmesinin neticeye etkili olmadığı şeklinde bir kabul dosya içeriğine uygun değildir. Ayrıca ölümü meydana getiren hepatitli kanın maktüle verilmesi olayında F'nin taksiri de mevcut değildir. Sonradan eklenen ortak sebep fiilin tabii sonucu ise; örneğin zatüre gelişmesi, aşırı kan kaybı, ameliyatın

11. Örnek Olay: A, öldürmek kastıyla B'ye ateş eder; ancak silahı bir atıştan sonra tutukluk yaptığı için atışlara devam edemez. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. B, hastanede tedavi görürken, aldığı yaraların daha önce var olan hastalığını tetiklemesi sonucunda ölür.

Bu gibi durumlarda 8. örnek olayda olduğu gibi, **tamamlanmış kasten öldürme suçundan** dolayı cezaya hükmetmek gerekir¹⁷⁹.

12. Örnek Olay: A, öldürmek kastıyla B'ye ateş eder; ancak silahı bir atıştan sonra tutukluk yaptığı için atışlara devam edemez. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. B, kendisine uygulanmak istenen tedaviyi çeşitli sebeplerle kabul etmez;

geç yapılması gibi hallerde olaya TCK'nın 81. maddesinin uygulanması ile birinci failin kasten öldürmeden sorumlu tutulması, aksi takdirde sonradan eklenen ortak sebep fiilin tabii sonucu değil ise ve failin de eklenen ortak sebebin eklenmesinde kusuru mevcut değil ise, örneğin ameliyat edilen hastanın serumuna zehir katılması, kullanılan kanın hepatitli olması, (bu kasten veya taksirle olabilir) kusursuz ceza olmaz ilkesi gereği 5237 s. TCK'nın 81, 35. maddeleri uygulanmak suretiyle konunun çözümü daha adil olacaktır."

Yargıtay C. Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname ile, bu hükmün **bozulması** talep edilir.

Ceza Genel Kurulu ise, aşağıdaki gerekçelerle bu hükmün **bozulmasına** oyçokluğu ile karar verir:

"Olayda F, öldürme kastı ile hareket etmiş ve ölüm neticesi de meydana gelmiştir. F'nin eylemi ile meydana gelen yara başlı başına ölüme yol açacak nitelikte olup, bu eyleme bağlı olarak ta ölüm neticesi gerçekleşmiştir. Meydana gelen ölüm neticesi, F'nin eyleminin doğal sonucu olup, F'nin eylemi ile başlattığı nedenler serisinden bağımsız gelişen bir netice olduğundan, F'nin eylemi ile ölüm neticesi arasında nedensellik bağı kesilmemiştir. Bu nedenle 5237 s. TCK kapsamında, F'nin tamamlanmış kasten öldürme suçunu işlediğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır."

Bu karara konu teşkil eden olayda F öldürmek kastıyla M'ye silahla ateş etmiştir. M ağır yaralanmıştır. M'de meydana gelen yaralar başlı başına ölüme yol açabilecek ağırlıktadır. Ancak M, ameliyata alınması sonucunda bağırsaklarında ve iç organlarında meydana gelen kopma ve yırtıkların tedavi edilmiş ve yaralarının iyileşmiş olmasına rağmen, ameliyat sırasında verilen kanla kendisine hepatit virüsü bulaşır ve bu nedenle bilahare ölmüştür.

Bu olayda F'nin fiili ile M'nin ölümü arasında **nedensellik bağının bulunduğu** hususunda kuşku yoktur. Ancak, bu illiyet bağının varlığı, meydana gelen ölüm sonucundan F'nin mutlak sorumlu tutulması gerektiği sonucunu doğurmaz.

M'ye hepatit virüsü bulunan kanın verilmesi, ceza hukuku bakımından sorumluluğu gerektiren bir durumdur. Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporunda ve Kararlarda, hepatit virüsü bulunan kanın M'ye verilmesinden dolayı F'nin dışında herhangi bir kişinin sorumlu tutulup tutulmayacağı konusunda hiçbir tartışma yapılmamaktadır. Özellikle Yüksek Mahkeme kararları bakımından bunun önemli bir eksiklik oluşturduğunu belirtmemiz gerekir.

Bu olayda da, F'nin kasıtlı fiili ile M'nin ölümü arasında nedensellik bağı vardır. Ancak, burada da **objektif isnadiyet** prensibinden hareketle, gerekli kontroller yapılmaksızın hepatit virüsü taşıyan kanın ameliyat sırasında M'ye verilmesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden, F'yi ceza hukuku bakımından sorumlu tutmamak gerekir. Bu olayda F'nin **kasten öldürme suçuna** (TCK, m. 81) **teşebbüsten** dolayı cezalandırılması gerekmektedir (Ayrıca bkz. KANGAL, Zeynel T.: *Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Objektif ve Sübjektif Isnadiyet*, İstanbul (tarihsiz), sh. 92 vd.).

¹⁷⁹ *Hakeri*, benzer durumlarda, A'nın *kasten öldürme suçuna teşebbüsten* dolayı cezalandırılması gerektiği fikrindedir (HAKERİ, Kasten Öldürme Suçları (2), sh. 28).

örneğin kendisine kan verilmesi gerekirken, dini inancı sebebiyle kan verilmesini kabul etmez ve sonuçta ölür.

Bu olayda da, A'nın kasıtlı fiili ile B'nin ölümü arasında nedensellik bağı vardır. Ancak, B'nin tedaviyi reddetmesi, meydana gelen ölüm neticesinin A'ya objektif olarak isnat edilmesine engel teşkil eder. Bu nedenle, A'nın sadece **kasten öldürme suçuna** (TCK, m. 81) **teşebbüsten** dolayı cezalandırılması gerekir.

13. Örnek Olay: A, öldürmek kastıyla B'ye ateş eder; ancak silahı bir atıştan sonra tutukluk yaptığı için atışlara devam edemez. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. Hastanede B'ye gerekli tıbbi müdahalede bulunulur. B, hastanede bir süre tedavisine devam edildikten sonra, tedavi ile bağlantılı olarak kendisine gerekli bilgilendirmeler yapılır ve belirli aralıklarla kontrole gelmek üzere evine gönderilir; ancak tedavi ile bağlantılı olarak kendisine yapılan uyarıları dikkate almadığı için yara enfeksiyon kapar ve sonuçta ölür.

12. örnek olayda olduğu gibi, bu olayda da, A'nın kasıtlı fiili ile B'nin ölümü arasında nedensellik bağı vardır. Ancak, B'nin izansızlığı, meydana gelen ölüm neticesinin A'ya objektif olarak isnat edilmesine engel teşkil eder. Bu nedenle, A'nın sadece **kasten öldürme suçuna** (TCK, m. 81) **teşebbüsten** dolayı cezalandırılması gerekir.

14. Örnek Olay: A, öldürmek kastıyla B'ye ateş eder; ancak silahı bir atıştan sonra tutukluk yaptığı için atışlara devam edemez. Yaralanan B, hastaneye kaldırılır. B, hastanede çıkan yangında kurtarılamayarak ölür.

Bu olayda da A hakkında sadece **kasten öldürme suçuna** (TCK, m. 81) **teşebbüsten** dolayı cezaya hükmetmek gerekir.

15. Örnek Olay: A, öldürmek kastıyla B'ye birkaç el ateş eder; B'nin aldığı yaralarla öldüğünü zannederek atışlarına devam etmez; işlediği suçun delillerini yok etmek ve gizlemek için, B'yi bir çukura gömer. B gerçekte, silah atışlarından aldığı yaralarla değil, gömüldüğü toprakta havasızlıktan ölür.

Bu olayda A'nın , B'nin ölüm sebebi konusunda yanlış olmasının ceza hukuku sorumluluğu üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. A'yı tamamlanmış kasten öldürme suçundan dolayı sorumlu tutmak gerekir.

Suçun tamamlanması için icra edilen fiilin yanısıra ayrıca bir neticenin gerçekleşmesinin gerekli olması halinde, **failin bu neticenin gerçekleşmesi kastıyla fiili icra etmesi yeterlidir**. Failin icra ettiği fiil ile netice arasında mevcut olan illiyet bağındaki sapmaların ceza hukuku sorumluluğu üzerinde herhangi bir etkisinin olmaması gerekir^{180,181}.

¹⁸⁰ CENTEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 307; KANGAL, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda ..., sh. 94; AKBULUT, Genel Hükümler (5), sh. 345. Bu itibarla, daha önceki görüşümüzden ayrılmış bulunmaktayız. Son olarak kitabımızın dördüncü basısında temsil ettiğimiz görüşte, failin icra ettiği fiille netice arasındaki nedensellik bağına ilişkin bilgi, kast kapsamında değerlendirilmekteydi. Buna göre nedensellik bağındaki önemsiz sapmalar, kastın

16. Örnek Olay: A, öldürmeye karar verdiği B'nin kafasına arkasından kalın bir demirle vurur. Yere yığılan B'nin öldüğünü düşünen A, olay yerinden ayrılır, arkadaşları C'ye olayı anlatır ve B'nin cesedini ortadan kaldırmasını ondan ister. C de bu istek üzerine B'yi toprağa gömer. B, toprak altında havasızlıktan ölür.

Bu olayda, A'nın fiilleri ile B'nin ölümü arasında nedensellik bağı mevcuttur. Bu olay bağlamında bir nedensellik bağı sorunu bulunmamaktadır. Bu durumda A'yı, 15. Örnek Olayda olduğu gibi, **tamamlanmış kasten öldürme suçundan** (TCK, m. 81) dolayı sorumlu tutmak gerekir. Bu bağlamda yukarıda 15. Örnek Olaya ilişkin açıklamalarımıza bakılmalıdır.

Bu olayda A, aynı zamanda C'yi TCK'nın 281. maddesinde tanımlanan **suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu** işlemeye azmettirmiştir. Ancak, kendi işlediği suçla ilgili olarak bu azmettirmede bulunduğu için, A bakımından suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu ile ilgili olarak bir **şahsi cezasızlık sebebi** söz konusudur (TCK, m. 281, f. 1, ikinci cümle).

C ise, bir fiil ile iki ayrı suç işlemiştir. C'nin işlediği birinci suç, kasıtlı bir suç olan **suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçudur**. Azmettiren sıfatıyla A bakımından bir şahsi cezasızlık sebebinin mevcut olması, C'nin bu suç sebebiyle fail sıfatıyla sorumluluğu üzerinde etkili olmaz. C'nin fiili aynı zamanda **taksirle ölüme sebebiyet verme suçunu** (TCK, m. 85, f. 1) oluşturmaktadır. C

varlığına halel getirmez. Bu görüş için bkz. DÖNMEZER/ERMAN II, no. 926; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 325; KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler (6), sh.153. *Ozansü*, bu gibi durumlarda A'nın sadece kasten öldürme suçuna teşebbüsten dolayı cezalandırılabilceği fıkriyedir (OZANSÜ, Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 97, 100). Ancak yazara göre, bu gibi durumlarda A'nın taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı da ceza sorumluluğu "gündeme gelebil"mektedir (OZANSÜ, Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 100).

¹⁸¹ Yargıtay'ın iktibas ettiğimiz şu kararında benimsenen görüşe iştirak etmiyoruz:

«... (S)anıkların eniştesi maktûl M'nin ... evde bütün aile fertlerine ulu orta küfür etmeğe başladığından; N'nin bu durumdan infiale kapılarak, eline geçirdiği *soba küreği ile rasgele maktûlin başına vurduğu*, kafa kemiklerinde kırık, çatlak oluşturmayan bu darbeden baygın hale gelen enişterinin öldüğü kanısına kapılan N ve kardeşi A'nın, onu birlikte sürükleyip evden çıkarak otoyol üst geçidinden aşağı attıkları (dosya münderecatından) anlaşılmış(tır. Ancak,) kafaya vaki darbenin beyinde nasıl bir etki husule getirdiği tespit edilememiş(tir). ... oluşa ve olayın akışına göre, sanıkta mukaddem öldürme iradesinin açığa çıkmadığı; ... cesedin sürüklenme ve atılma sırasında maruz kaldığı tahribattan da ölümün husulünün varidi ihtimal olduğu anlaşılmakla; sanığın, müessir fiil sonucu ölüme sebebiyetten dolayı, (mülga 765 s.) TCK'nın 452/1. maddesiyle tecziyesi» gerekir: 1.CD, 17.11.1987, 3243/4006 (YKD, Nisan 1988, 554 vd.).

Bir insanın kafasına kürekle vurulması durumunda, kafaya vurulan darbelerin insanın ölümüne sebebiyet verebileceği muhtemeldir. Başka bir deyişle, bir insanın kafasına sert bir cisimle vuran kişi, insan *öldürmeye yönelik muhtemel kastla* hareket etmektedir.

Bu şekilde ika edilen fiil sonucunda mağdurun öldüğü zannedilmiştir. Cesedi ve suçun delillerini ortadan kaldırmak isteyen kişiler, mağduru otoyol üst geçidinden aşağıya atmışlardır. Mağdur, gerçekte, otoyol zeminine çarparak ölmüştür.

Bu olayda illiyet bağında bir yanlış söz konusudur. Ancak, bu yanlışlığın, kişilerin muhtemel kastla işledikleri öldürme suçundan sorumlu tutulmaları açısından bir etkisi bulunmamaktadır.

gerekli dikkat ve özeni göstermiş olsaydı B'nin ölmediğini, baygın bir vaziyette yere yığıldığını anlardı ve onu toprağa gömerek ölümüne sebebiyet vermezdi. Bu durumda C'yi TCK'nın 44. maddesindeki **farklı neviden fikri içtima** hükmü gereği olarak bunlardan sadece daha ağır cezayı gerektiren suç (**taksirle ölüme sebebiyet verme suçu**) dolayısıyla sorumlu tutmak ve cezalandırmak gerekir¹⁸².

17. Örnek Olay: Aralarında çıkan tartışmada öfkelenen A, B'nin kafasına bir yumruk vurur. Beyin kanaması geçiren B, bayılır ve yere düşer. B'nin öldüğünü düşünen ve korkuya kapılan A, olay yerinden ayrılır, arkadaşı C'ye olayı anlatır ve B'nin cesedini ortadan kaldırmasını ondan ister. C de bu istek üzerine B'yi toprağa gömer. B, toprak altında havasızlıktan ölür.

Bu olayda, A'nın fiilleri ile B'nin ölümü arasında nedensellik bağı mevcuttur. Bu olay bağlamında bir nedensellik bağı sorunu bulunmamaktadır. Ancak, bu durumda A'yı sadece **neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama suçun-**dan (TCK, m. 87, f. 4) dolayı sorumlu tutmak gerekir.

A'nın **suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu** dolayısıyla sorumluluğu ile ilgili olarak 16. Örnek Olay bağlamında yapmış bulunduğumuz açıklamalar, bu Örnek Olay bakımından da aynen geçerlidir.

Keza C'nin sorumluluğu ile ilgili olarak 16. Örnek Olay bağlamında yapmış bulunduğumuz açıklamalar, bu Örnek Olay bakımından da aynen geçerlidir.

18. Örnek Olay: A, yaralamak kastıyla B'ye ateş eder: B, A'nın silahından çıkan kurşunların vücuduna isabeti suretiyle oluşan yaraların, daha önce var olan hastalığını tetiklemesi sonucunda ölür.

Bu olayda A'nın yaralama fiiliyle B'nin ölümü arasında nedensellik bağı vardır. Ancak, aşağıda açıklayacağımız üzere, A'nın, B'nin ölümünden sorumlu tutulabilmesi için, netice sebebiyle ağırlaştırılmış suçlarda gerçekleşen ağır neticeden sorumluluğa ilişkin manevi unsur bakımından aranan koşulun (TCK, m. 23) gerçekleşmesi gerekmektedir.

19. Örnek Olay: A, yaralamak kastıyla C'ye ateş eder: A'nın silahından çıkan kurşunlarla yaralanan C, B'nin kullandığı araçla tedavi için hastaneye kaldırılır. B'nin hızlı araç kullanması ve trafik işaretlerine riayet etmemesi sebebiyle oluşan ikinci trafik kazasında C, ölür.

Bu olayda da A'nın yaralama fiili ile C'nin ölümü arasında nedensellik bağı vardır. Ancak, sadece nedensellik bağının varlığı A'nın gerçekleşen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için yeterli değildir. Ayrıca, bu neticenin, A'ya objektif olarak isnat edilebilmesi gerekir. Bu itibarla, B'nin dikkatsiz ve özensiz araç kullanması sebebiyle oluşan trafik kazasında C'nin ölmüş olmasından, A'yı ceza

¹⁸² AKBULUT, Genel Hükümler (5), sh. 346.

hukuku bakımından sorumlu tutmamak gerekir. Bu olayda A'nın **kasten yaralama suçundan** (TCK, m. 86, 87) dolayı, B'nin ise **taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan** (TCK, m. 85) dolayı cezalandırılması gerekmektedir.

20. Örnek Olay: A, şehir içinde azami hız sınırını aşarak araç kullandığı için, yaya B'ye çarpar. Dengesini kaybeden B, düşerek başını yere çarpar.

Birinci ihtimal: Başından hafif bir şekilde yaralanan B, kendisiyle ilgili olarak hayati bir tehlike olduğunu düşünmez ve herhangi bir kişi tarafından böyle bir tehlikenin bulunduğu ve hastaneye başvurması gerektiği hususunda kendisine bir tavsiye ve uyarıda bulunulmaz. Tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvuran B, beyin kanaması sonucu ölür.

Bu ihtimalde, A'yı **taksirle öldürme suçundan** (TCK, m. 85) dolayı sorumlu tutmak gerekir. B'nin, yarasının kendisiyle ilgili olarak hayati tehlike oluşturduğunu düşünmemiş ve bu nedenle bir sağlık kuruluşuna başvurmamış olması, A'nın taksirle öldürme suçundan (TCK, m. 85) dolayı sorumluluğu üzerinde etkili olmaz.

İkinci ihtimal: B, hayati tehlikesinin varlığı sebebiyle kendisine tavsiye ve uyarıda bulunulmasına rağmen, bir şey olmaz düşüncesiyle, tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal eder ve beyin kanaması sebebiyle ölür.

Bu ihtimalde, B kendisine tavsiye ve uyarılarda bulunulmasına rağmen tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal eder. Bu nedenle, B'nin ölümünden dolayı A'yı sorumlu tutmamak gerekir. A'nın sadece **taksirle yaralama suçundan** (TCK, m. 89) dolayı sorumluluğu cihetine gitmek gerekir¹⁸³.

Üçüncü ihtimal: B, hayati tehlikesi nedeniyle, tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurur; ancak, hekim kendisine gerekli tıbbi müdahalede bulunmaz ve beyin kanaması sebebiyle ölür.

Bu ihtimalde, hekim tarafından hastaya gerekli tıbbi müdahalede bulunulmamıştır. Hekim hastaya gerekli **tıbbi müdahalede bulunmayı kasten ihmal etmiş** ise, meydana gelen ölüm neticesinden hekimi TCK'nın 83. maddesi hükümlerine istinaden sorumlu tutmak gerekir. Buna karşılık A'nın ise, **taksirle yaralama suçundan** (TCK, m. 89) dolayı sorumluluğu cihetine gitmek gerekir.

Sağlık kuruluşuna başvuran B'ye işlerin yoğunluğu, hasta sayısının fazlalığı nedeniyle, gerekli tıbbi müdahalede bulunulmakta gecikilmiş olabilir. Bu durumda, B'nin beyin kanaması sebebiyle ölümünden dolayı sağlık görevlilerinin sorumluluğu cihetine gidilemez. Buna karşılık, A'yı ise **taksirle öldürme suçundan** (TCK, m. 85) dolayı sorumlu tutmak gerekir.

Dördüncü ihtimal: B, hayati tehlikesi nedeniyle, tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurur ve fakat yarası sadece pansuman edilerek taburcu edilir ve bilahare beyin kanaması sebebiyle ölür.

¹⁸³ AKBULUT, Genel Hükümler (5), sh. 349.

Bu ihtimalde, hekim tarafından teşhis bağlamında gerekli dikkat ve özen gösterilmemiştir. Başka bir ifadeyle, gerekli dikkat ve özeni gösterilmiş olsaydı, B'nin yarasının hayati tehlike arz eder boyutta olduğu tespit edilirdi ve buna göre tedavi uygulanırdı. Bu ihtimalde A'nın **taksirle yaralama** suçundan (TCK, m. 89) dolayı, hekimin ise **taksirle ölüme sebebiyet vermekten** dolayı (TCK, m. 85) sorumluluğu cihetine gitmek gerekir.

Dikkat edilmelidir ki, bütün bu ihtimallerde bir nedensellik bağı sorunu bulunmamaktadır. Bütün bu ihtimallerde A'nın fiili ile B'nin ölümü arasında nedensellik bağı vardır. Ancak bazı ihtimallerde, meydana gelen ölüm neticesini A'ya objektif olarak isnat edememekteyiz; bu nedenle, A'yı sadece taksirle yaralama suçundan dolayı sorumlu tutmaktayız.

21. Örnek Olay: A, gece serbest bıraktığı çoban köpeğini sabahleyin zincire bağlamayı ihmal eder. Bu sırada köpek, işine gitmekte olan B'ye saldırır ve B'yi yaralar.

Birinci ihtimal: B, kendisiyle ilgili olarak kuduz tehlikesinin olduğunu düşünmez ve herhangi bir kişi tarafından böyle bir tehlikenin bulunduğu ve tedavi görmesi gerektiği hususunda kendisine bir tavsiye ve uyarıda bulunulmaz. Tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurmayan B, kuduz sebebiyle ölür.

Bu ihtimalde, A'yı **taksirle öldürme** suçundan (TCK, m. 85) dolayı sorumlu tutmak gerekir. B'nin, kendisiyle ilgili olarak kuduz tehlikesinin olduğunu düşünmemiş ve bu nedenle bir sağlık kuruluşuna başvurmamış olması, A'nın taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan (TCK, m. 85) dolayı sorumluluğu üzerinde etkili olmaz.

İkinci ihtimal: B, kuduz tehlikesinin varlığına rağmen ve kendisine tavsiye ve uyarıda bulunulduğu halde, bir şey olmaz düşüncesiyle, tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal eder ve kuduz sebebiyle ölür.

Bu ihtimalde, B kendisine tavsiye ve uyarılarda bulunulmasına rağmen tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal eder. Bu nedenle, B'nin ölümünden dolayı A'yı sorumlu tutmamak gerekir. A'nın sadece **taksirle yaralama** suçundan (TCK, m. 89) dolayı sorumluluğu cihetine gitmek gerekir.

Üçüncü ihtimal: B, kuduz tehlikesi nedeniyle, tedavi için bir sağlık kuruluşuna gider; ancak, yolda geçirdiği bir trafik kazasında ölür.

Köpek tarafından ısırılan B'nin kuduz tedavisi için hastaneye giderken meydana gelen trafik kazasında ölümünden dolayı A'yı ceza hukuku bakımından sorumlu tutamayız. Bu ihtimalde A'nın sadece **taksirle yaralamaya** sebebiyet vermek suçundan (TCK, m. 89) dolayı cezalandırılması gerekmektedir.

Dördüncü ihtimal: B, kuduz tehlikesi nedeniyle, tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurur; ancak, hekim kendisine gerekli tıbbi müdahalede bulunmaz ve kuduz sebebiyle ölür.

Bu ihtimalde, hekim tarafından hastaya gerekli tıbbi müdahalede bulunulmamıştır. Hekim hastaya gerekli **tıbbi müdahalede bulunmayı kasten ihmal** etmiş ise, meydana gelen ölüm neticesinden hekimi TCK'nın 83. maddesi hükümlerine istinaden sorumlu tutmak gerekir. Buna karşılık A'nın ise, **taksirle yaralama** suçundan (TCK, m. 89) dolayı sorumluluğu cihetine gitmek gerekir.

Beşinci ihtimal: B, kuduz tehlikesi nedeniyle, tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurur ise de, hekimin uyguladığı yanlış tedavi sonucunda ölür.

Bu ihtimalde, hekim tarafından teşhis ve tedavi bağlamında gerekli dikkat ve özen gösterilmemiştir. Başka bir ifadeyle, gerekli dikkat ve özeni gösterilmiş olsaydı, B'nin yarasının pansuman edilmesiyle yetinilmez, kuduz tedavisi için gerekli aşıların yapılması cihetine gidilirdi. Bu ihtimalde A'nın **taksirle yaralama** suçundan (TCK, m. 89) dolayı, hekimin ise **taksirle ölüme sebebiyet vermekten** dolayı (TCK, m. 85) sorumluluğu cihetine gitmek gerekir.

Altıncı ihtimal: B, kuduz tehlikesi nedeniyle, tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurur ve kendisine gerekli tıbbi tedavi uygulanır; ancak, tedavi sürecinde uygulanan ilacın sebebiyet verdiği öngörülmeleyen bir komplikasyon sonucu ölür.

Bu ihtimalde, teşhis ve tedavi bağlamında gerekli dikkat ve özen gösterilmiştir. Ancak hasta (B), uygulanan ilacın sebebiyet verdiği ve fakat hekim tarafından öngörülmeleyen bir komplikasyon sonucu ölmüştür. Bu itibarla, tedaviyi uygulayan hekim, B'nin ölümünden ceza hukuku bakımından sorumlu tutulamaz. Ancak, öngörülemelik sebebiyle hekimin ceza hukuku bakımından sorumlu tutulmaması, B'nin ölümü dolayısıyla ilacı üreten ve satan şirket ile ilgili sağlık kuruluşunun tazminat sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Buna karşılık, A'nın ise, sadece **taksirle yaralama** suçundan (TCK, m. 89) dolayı sorumluluğu cihetine gitmek gerekir. B'nin tedavi sürecinde uygulanan ilacın sebebiyet verdiği bir komplikasyon sonucu ölümünden A'yı ceza hukuku bakımından sorumlu tutamayız.

Söz konusu olayda B'nin yaralanması ve ölümü neticesi bakımından doğal bir fenomen olan bir nedensellik bağı sorunu bulunmamaktadır. Bütün bu ihtimallerde sorun, B'nin yaralanması ve ölümünün A'ya objektif olarak isnat edilebilip edilemeyeceği sorunudur, yani normatif bir değerlendirmeyi gerekli kılan **objektif isnadiyet sorunudur**.

IV. Fail

A. “Özgü (Mahsus) Suç” Kavramı

Ceza kanunlarında tanımlanan suçlar kural olarak, *herkes* tarafından işlenebilen suçlardır. Kanunî tanımında faille bağlantılı olarak “... kişi ...”, “... kimse ...”, “*bir kimse* ...” veya “*her kim* ...” ifadelerinin kullanıldığı suçlar, bu nitelikte suçlardır.

Buna karşılık, bazı suçlar özel bir yükümlülük altında bulunan ve belli faillik vasfını taşıyan kişiler tarafından işlenebilirler. Meselâ Kanunun İkinci Kitap,

Dördüncü Kısım, “*Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar*” başlıklı Birinci Bölümünde yer alan suçların çoğunda, ancak *kamu görevlisi* olan kişiler (m. 6, f. 1, bent c) fail olabilir.

Kanunî tarifinde faille ilgili olarak, herhangi bir insan olmanın ötesinde, belli *özel ve objektif vasıflardan* söz edilen suçlara, *özü (mahsus) suç* denmektedir.¹⁸⁴ Özü suçlarda suçun faili, diğer insanlara nazaran *özel bir yükümlülük* altında bulunmaktadır.

Meselâ, bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu görev dolayısıyla bir *kamu hukuku yükümlülüğü* altına girmektedir. Buna göre, kamu görevlileri, üstlendikleri kamu görevinin yürütümü sırasında, bu faaliyetin gerekli kıldığı yükümlülüklerle uygun hareket etmek zorundadırlar. Öyle ki; *toplumda hakim olan kamu faaliyetlerinin gerek eşitlik¹⁸⁵ gerek liyakatlilik¹⁸⁶ açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez olduğu, başka bir ifadeyle, satın alınamayacakları¹⁸⁷ konularındaki güvenin, inancın sarsılmaması gerekir¹⁸⁸.*

Ancak özel yükümlülük altındaki kişilerin fail olabileceği suçlara *yükümlülük suçları* da denmektedir.¹⁸⁹

Özü suçlardan bazıları münhasıran özel faillik vasfını taşıyan kişiler tarafından işlenebilirler. Meselâ, görevi kötüye kullanma suçunun faili, ancak kamu görevlisi olan kişiler olabilir (m. 257). Bu suçlara *gerçek özü suçlar* denir.

Özü suçlar, bazen suçun bir nitelikli şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Suçun basit şekli herkes tarafından işlenebilirken, nitelikli şekli ancak belli özel faillik vasfını taşıyan kişi tarafından işlenebilir. Bu grup özü suçlara *görünüşte özü suçlar*¹⁹⁰ denilmektedir. Meselâ resmî evrakta sahtekârlık suçu herkes tarafından işlenebilir (m. 204, f. 1). Ancak, bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, faile daha ağır bir ceza verilmektedir (m. 204, f. 2).

Özel faillik vasfı, suça iştirakte sorumluluk statülerinin belirlenmesinde büyük bir önem taşımaktadır (*Bağlılık kuralı*: m. 40).

¹⁸⁴ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 90.

¹⁸⁵ Iustitia commutativa, "ADL" adaleti, denkleştirici adalet.

¹⁸⁶ Iustitia distributiva, "KIST" adaleti, tevzi edici, üleştirici adalet.

¹⁸⁷ "Unbestechlichkeit von Amtsträgern"

¹⁸⁸ ÖZGENÇ: *Kamu Görevi, Yükümlülük Suçları, Yükümlülük Suçlarına İştirak (Karar İncelemesi)*, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 4, yıl 1994, sayı 1-2, sh. 334. Bu hususta ayrıca bkz. ERMAN, Erman/Özek, sh. 1/2.

¹⁸⁹ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 165 vd.

¹⁹⁰ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, sh. 91.

B. Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olabilmesi Sorunu

Bir fiilin varlığından söz ederken bunun mutlaka bir insanla ilişkilendirilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle, fiil ancak bir insan tarafından işlenebilir. Bu itibarla, bir suçun faili ancak bir insan olabilir.

Tüzel kişi, bir suçun faili olamaz. Tüzel kişinin suçun faili olup olamaması ile, işlenen suç dolayısıyla tüzel kişi hakkında ceza hukuku yaptırımının uygulanıp uygulanamaması, birbirinden farklı olarak ele alınması gereken sorunlardır.

Tüzel kişinin genel anlamda suçun faili olamaması, azmettiren veya yardım eden olarak suça iştirak edememesi, tüzel kişi hakkında **ceza yaptırımını** uygulanamaması sonucunu doğurur. Buna karşılık, bir suçun tüzel kişinin yararına olarak veya tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde, tüzel kişinin organ veya temsilcisi ya da herhangi bir çalışanı tarafından işlenmiş olması halinde, bu tüzel kişi hakkında da **güvenlik tedbiri** olarak birtakım ceza hukuku yaptırımları uygulanabilecektir. Ancak, işlenen bir suç sebebiyle tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri olarak bir ceza hukuku yaptırımına hükmedilebilmesi, tüzel kişinin suçun faili olabileceği sonucunu doğurmamaktadır¹⁹¹.

Tüzel kişinin fiil ehliyeti olmadığına göre, kusur ehliyetine de sahip olmadığını evleviyetle söyleyebiliriz¹⁹². Çünkü, kusur ehliyetine sahip olabilmek için, önce fiil ehliyetine sahip olmak gerekir. Haksızlık olarak değerlendirilen bir fiil dolayısıyla bu fiil failinin muaheze edilmesi gerektiği konusundaki yargıyı ifade eden kusurun bir tüzel kişiye atfı hiçbir surette mümkün değildir.

¹⁹¹ Doktrinde, tüzel kişi hakkında bir ceza hukuku yaptırımı olarak güvenlik tedbiri uygulanabilmesinden hareketle, tüzel kişinin de suçun faili olabileceği görüşü ileri sürülmüştür (ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 3. bası, sh.270).

Keza, ceza hukuku yaptırımlarından hapis cezasının tüzel kişiler hakkında uygulanamamasına karşılık, adli para cezasının uygulanabileceği düşüncesinden hareketle de, tüzel kişinin suçun faili olabileceği fikirleri ileri sürülmüştür. Bu fikirde olanlar, tüzel kişi hakkında verilebilecek olan kapatma kararının da tüzel kişilere özgü bir ceza olduğunu ileri sürmektedirler.

Tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan yaptırımlardan hareketle, tüzel kişinin suçun faili olabileceği sonucuna varan görüş, bünyesinde önemli bir mantık hatasını ihtiva etmektedir. İdam cezası ile mukayese ederek tüzel kişi hakkında verilen kapatmanın da ceza olduğunu kabul eden anlayış, kapatmanın bir tedbir mahiyeti taşıdığı gerçeğini gözardı etmektedir. Belli bir miktar paranın Devlet hazinesine ödenmesini ifade eden adli para cezasının tüzel kişilere de uygulanabileceğini savunan bu anlayış, paranın devlet hazinesine ödenmemesi halinde, adli para cezasına ilişkin infaz hükümlerinin tüzel kişiler bakımından uygulanamaması gerçeğini gözardı etmektedirler.

Tüzel kişilerin suçun faili olabileceğini kabul edenler, mahiyeti itibarıyla tüzel kişinin cinsel suçlar gibi bazı suçları işleyemeyeceği; buna karşılık kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, parada sahtecilik gibi suçlar bakımından tüzel kişinin de fail olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde fikirleri ileri sürmektedirler. **Anayasa Mahkemesinin** de mülga 765 sayılı TCK döneminde vermiş bulunduğu bir kararla (14.2.1989, E. 1988/15, K. 1989/9, RG: 4 Şubat 1991/20776) iştirak ettiği bu fikirlerin tutarsızlıkları, Kitabımızın 11. ve daha önceki basılarında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır (Bkz. 11. bası, sh. 193 vd.)

¹⁹² ESER, Albin: Schönke/Schröder(23), §75, kn. 8. Aynı şekilde ÖZTAN, Bilge: *Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk*, Ankara, 1970, sh. 135.

Fiil ehliyeti olmayan ve dolayısıyla, suç faili olamayacak olan tüzel kişilerin *cezaî sorumluluğu mevcut değildir*.¹⁹³ Cezanın gerek kefarete özelliği, gerek önleme etkisi, ancak *gerçek kişiler*, yani *insanlar* açısından söz konusudur. Bizzat tüzel kişi açısından cezanın ne kefarete özelliğinden ne de önleme etkisinden bahsetmek mümkündür.¹⁹⁴

C. Suç Nedeniyle Tüzel Kişinin Sorumluluğu

Tüzel kişi, suç faili olamamakla birlikte, bir suç tüzel kişinin yararına olarak veya faaliyeti çerçevesinde işlenebilmektedir. Aşağıda Yaptırım Teorisi bağlamında yapacağımız açıklamalarda da görüleceği gibi, bir suçun tüzel kişinin yararına olarak veya faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bu tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilmektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu gibi durumlarda suçun faili tüzel kişi değil, tüzel kişinin organlarında görev yapan, tüzel kişinin temsilcisi sıfatını taşıyan veya tüzel kişinin faaliyetleri çerçevesinde herhangi bir şekilde görevlendirilmiş olan bir **gerçek kişidir**.

Keza, 5326 s. *Kabahatler Kanununa* 26.6.2009 tarihli ve 5918 sayılı Kanunla¹⁹⁵ “Tüzel kişilerin sorumluluğu “ başlığıyla 43/A maddesi eklenmiştir:

“MADDE 43/A–(1) *Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından;*

a) 5237 sayılı *Türk Ceza Kanununun*;

1) 157’nci ve 158’inci maddelerinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun,

2) 235’inci maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunun,

3) 236’ncı maddesinde tanımlanan edimin ifasına fesat karıştırma suçunun,

4) 252’nci maddesinde tanımlanan rüşvet suçunun,

5) 282’nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun,

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı *Bankacılık Kanununun* 160’ıncı maddesinde tanımlanan zimmet suçunun,

c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı *Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda* tanımlanan kaçakçılık suçlarının,

¹⁹³ CRAMER, Peter: Schönke/Schröder(23), Vorbem. vor §§ 13 ff., kn. 99; BLAUTH, sh. 9.

¹⁹⁴ Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararının verildiği tarih (1989) itibarıyla Türk ceza hukukunun gelişmişlik düzeyinin etkisiyle, bu kararda ceza hukuku yaptırımları arasındaki ceza ve güvenlik tedbiri ayrımı ve keza, adli ve idarî para cezası ayrımı, göz ardı edilmiştir. Ayrıca, söz konusu kararda, bir suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişinin ceza hukuku sorumluluğu ile tüzel kişinin suçun faili olamayacağı hususları birbirine karıştırılmıştır.

¹⁹⁵ Resmi Gazete: 9 Temmuz 2009/27283.

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 5'inci maddesinde tanımlanan suçun,

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8'inci maddesinde tanımlanan terörün finansmanı suçunun,

tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk Lirasından ikimilyon Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(2) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan suçlardan dolayı yargılama yapmakla görevli **mahkeme** yetkilidir. ”

26.6.2009 tarihli ve 5918 sayılı Kanuna ilişkin 7.1.2009 tarihli ve Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü B.02.0.KKG.0.10/101-1619/37 sayılı Tasarıda Kabahatler Kanununa eklenmesi öngörülen söz konusu 43/A madde şu şekilde idi:

“Tüzel kişilerin sorumluluğu

MADDE 43/A- (1) Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından;

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;

1) 157'nci ve 158'inci maddelerinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun,

2) 235'inci maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunun,

3) 236'ncı maddesinde tanımlanan edimin ifasına fesat karıştırma suçunun,

4) 252'nci maddesinde tanımlanan rüşvet suçunun,

5) 282'nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun,

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160'ıncı maddesinde tanımlanan zimmet suçunun,

c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan kaçakçılık suçlarının,

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 5'inci maddesinde tanımlanan suçun,

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8'inci maddesinde tanımlanan terörün finansmanı suçunun,

Tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk Lirasından birmilyon Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(2) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan suçlardan dolayı yapılan yargılama sonucunda hükmü kuran mahkeme yetkilidir. ”

Söz konusu Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısında bu maddenin **gerekçesi** olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

*“Türk Ceza Kanununun 20’nci maddesinde tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamayacağı, ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanabileceği düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununun 60’ıncı maddesinde ise tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbiri olarak faaliyet izninin iptali ve müsadere kararı verilebileceği düzenlenmiştir. Bir özel hukuk tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde ve bu tüzel kişinin yararına olarak bir suç işlenmesi halinde, tüzel kişi bakımından adli para cezasına hükmetmek mümkün değilse de, bu tüzel kişilerin faaliyetlerinin hukuk zemininde disipline edilebilmesini temin amacıyla, **organlarını oluşturan veya temsilcisi sıfatını taşıyan kişilerin en azından dikkat ve özen yükümlülüğünü vurgulamak için**; belirli suçların bir özel hukuk tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, bu suçları işleyen kişiler hakkında mahkumiyet kararı verildiği takdirde, ayrıca bu tüzel kişi hakkında da idari para cezası verilebilmesine imkan tanımak gerekmiştir. Yapılan düzenlemede, tüzel kişinin yararına olarak işlenen suçlar sayma yöntemi ile belirlenmiştir.*

Yolsuzlukla mücadele ile ilgili olarak taraf olduğumuz sözleşmeler bakımından uluslararası alanda maruz kaldığımız eleştirilerin önüne geçmek amacıyla, Kabahatler Kanununa eklenen yeni bir maddeyle, bir özel hukuk tüzel kişinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından, yolsuzluk olarak nitelenen bazı suçların tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, tüzel kişiye de idarî para cezası verilmesine imkan tanınmıştır.”¹⁹⁶

Tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri sırasında, Kabahatler Kanununa eklenmesi öngörülen söz konusu madde metninde kanunlaşan şekliyle değişiklik yapılmıştır. TBMM Adalet Komisyonunun söz konusu Kanun Tasarısına ilişkin 16.4.2009 tarihli ve Esas 1/670, Karar 22 sayılı Raporunda bu değişikliğin gerekçesi olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Tasarının çerçeve 8’inci maddesiyle, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 43’üncü maddeden sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen 43/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birmilyon” liralık idari para cezası, Komisyonumuzca yetersiz bulunarak “ikimilyon” liraya yükseltilmiş, ayrıca ikinci fıkrasında verilen önerge doğrultusunda aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmıştır. Kabahatler Kanununa eklenmesi öngörülen 43/A maddesiyle, özel hukuk tüzel kişinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilcisi olmamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen

¹⁹⁶ TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 353.

bir kişi tarafından, yolsuzluk olarak nitelenen bazı suçların bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, tüzel kişiye de idari para cezası verilmesine imkan tanınmaktadır. Maddede yer alan suç tiplerinin içerdiği ekonomik değerin çok yüksek olması nedeniyle, cezanın caydırıcılığının sağlanması amacıyla tüzel kişiler için öngörülen idari para cezasının üst sınırının artırılması uygun olacaktır. Bu para cezasının tespitinde doğaldır ki Kabahatler Kanununun 17'nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, kabahatin haksızlık içeriği ile tüzel kişinin organlarını oluşturan veya temsilcisi sıfatını taşıyan kişilerin kusuru ve tüzel kişinin ekonomik durumu dikkate alınacaktır. Öte yandan Kabahatler Kanununa eklenmesi öngörülen 43/A maddesinin ikinci fıkrasında, idari para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan suçlardan dolayı yapılan yargılama sonucunda hüküm kuran mahkemenin yetkili olduğu düzenlenmiştir. Ancak, madde metnindeki "hükmü kuran" ibaresi, tüzel kişiye idari para cezası verilebilmesi için, mutlaka kovuşturma aşamasının tamamlanarak bir hükümle yargılamanın bitirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum ise maddede sayılan suçlardan birinin işlendiği ve işlenen suçtan dolayı tüzel kişinin bir yarar elde ettiğinin tespit edilmesine rağmen; herhangi bir nedenle kovuşturmanın başlayamaması veya başlayan kovuşturmanın mahkumiyetle sonuçlanmaması durumlarında tüzel kişiye idari para cezası verilemeyeceği gibi bir netice ortaya çıkarmaktadır. Bu duruma engel olmak amacıyla fıkra da değişiklik yapılmıştır."¹⁹⁷

D. Kabahatlerden Dolayı Tüzel Kişinin Sorumluluğu

Tüzel kişinin kamu hukuku alanında sorumluluk rejimi bakımından önem arz etmesi itibarıyla, 5326 s. Kabahatler Kanununun "Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk" başlıklı 8. maddesi hükmünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu madde metninde şu hükümlere yer verilmiştir:

"(1) Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir.

(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir.

(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kişide özel nitelikler aradığı hallerde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

¹⁹⁷ TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 353, sh. 19.

(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli olmaması halinde de uygulanır.”

Bu maddenin gerekçesi şu şekildedir:

“Madde metninde, tüzel kişi hakkında da kabahat dolayısıyla idari yaptırım ve bu bağlamda idari para cezası uygulanabileceği kabul edilmiştir. Yeni Türk Ceza Kanununun sisteminde tüzel kişi hakkında suç dolayısıyla ceza yaptırımı uygulanamaz. Buna karşılık, idari para cezasının niteliği ve amacının farklılığı dolayısıyla, bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen kabahat nedeniyle bu tüzel kişiye de idari para cezası verilebilecektir.

Tüzel kişi hakkında idari yaptırım uygulanabilmesi, organ veya temsilci sıfatıyla tüzel kişi adına hareket eden ya da tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde istihdam edilen kişi hakkında da idari yaptırım uygulanmasına engel teşkil etmez. Bu durumda tüzel kişi ile gerçek kişilere verilen idari para cezasının tahsili açısından müteselsil sorumluluk da kabul edilemez. İdari para cezası, bir ceza hukuku yaptırımı niteliği taşımamakla birlikte; bir kamu hukuku yaptırımı olması dolayısıyla ve uygulanmasıyla güdülen amacın gerçekleşebilmesi için ancak hakkında uygulanan kişi üzerinde etkili olabilmelidir. Bu bakımdan, Tasarının sisteminde, işlenen kabahat nedeniyle verilen idari para cezası ile ilgili olarak müteselsil sorumluluk kabul edilmemiştir.

Maddenin bir ve ikinci fıkraları hükümlerinde bu düşünceler esas alınmıştır.

Üçüncü fıkra göre, suçlardan farklı olarak, iştirak ilişkisinde tek tip faillik sisteminin benimsendiği kabahatlerde, özel faillik niteliğini taşıyan kişinin yanı sıra, bu niteliği taşımayan kişi de, fail olarak sorumlu tutulacaktır.

Dördüncü fıkra, organ veya temsilci sıfatıyla ya da hizmet ilişkisine dayanarak gerçekleştirilen fiiller açısından özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, organ veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlem herhangi bir nedenle bilahare hukuka aykırı bulunarak iptal edilebilir. Ancak, buna rağmen iptal öncesinde gerçekleştirilen kabahatler açısından bu madde hükümlerine göre idari yaptırım sorumluluğu devam eder.”¹⁹⁸

Ancak, bu düzenlemenin mevzuatta birtakım istisnaları mevcuttur.

Şöyle ki, Kabahatler Kanununun 8. maddesine göre, “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir.” Ancak, örneğin bir tüzel kişi ile aralarındaki hizmet ilişkisinin gereği olarak bu tüzel

¹⁹⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840.

kişiye ait motorlu araçla trafiğe çıkan sürücünün trafik kurallarına aykırı araç kullanması halinde, 2918 s. *Karayolları Trafik Kanunu* hükümlerine göre kural olarak sadece bu sürücü hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak, sürücünün kim olduğunun tespit edilememesi halinde, aracın adına tescil olduğu tüzel kişiye araç plakası üzerinden idari para cezası verilmektedir.

Keza, örneğin 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, bu kanundan kaynaklanan yükümlülükler aykırılık halinde sadece ilgili tüzel kişi hakkında idari para cezası verilmektedir¹⁹⁹. Ayrıca bu tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişiler hakkında idari para cezası uygulanmamaktadır.

V. Suçun Konusu

Suçun maddi unsurlarından beşincisini de konu oluşturmaktadır. Konusuz suç olmaz²⁰⁰. *Suçun konusu*²⁰¹, eşya veya şahsın fizikî, maddi yapısıdır, bünyesidir. Bazı suç tanımlarından konuyu bir nesnenin oluşturduğu, açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Örneğin, hırsızlık suçunda “*taşınır bir mal*” (m. 141, f. 1), mala zarar verme suçunda “*taşınır veya taşınmaz mal*” (m. 151, f. 1), güveni kötüye kullanma (m. 155, f. 1) ve zimmet (m. 247, f. 1) suçlarında “*mal*” gibi.

Bazı suçlarda konu ile mağdur, iç içe olmakla birlikte aynı şeyler değildir²⁰². Örneğin, kasten yaralama suçunda (m. 86, f. 1) mağdur, yaralanan *kişidir*; konu ise, bu kişinin *vücududur*. Hakaret suçunda (m. 125, f. 1) mağdur, hakaret edilen *kişidir*; konu ise, bu kişinin *şerefidir*.

¹⁹⁹ Bazı adli cezalar mahiyet itibarıyla tüzel kişi bakımından uygulanamaz olmakla birlikte, idari para cezası gibi adli para cezasının da tüzel kişiye verilebileceği ileri sürülebilir. Ancak, idari para cezasından farklı olarak, adli para cezasının infazı bağlamında önemli sorunlarla karşı karşıya kalınacağı göz ardı edilmemelidir.

²⁰⁰ Ancak, Türk doktrinde bazı yazarlar, konusu olmayan suçların da varlığını kabul etmektedirler (TOROSLU, Nevzat: *Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu*, Ankara, 1970, sh. 190; ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 144). Fakat bu yazarlar konusu olmayan suçlara ilişkin olarak başka bir açıklamada bulunmamaktadırlar. Başka bir ifadeyle, adı geçen yazarlar konusu olmayan suçlarla ilgili olarak örnek göstermemektedirler.

²⁰¹ Doktrinde, *suçun konusu* kavramına karşılık olarak, “suçun maddi konusu”; *hukuki değer* kavramına karşılık olarak ise, “suçun hukuki konusu” ifadeleri de kullanılmaktadır (Bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 234 vd.; SOYASLAN, Doğan: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 3. bası, Ankara, 2005, sh. 227 vd.; aynı yazar: *Ceza Hukuku Özel Hükümler*, 2. bası, Ankara, 1997, sh. 36 vd.). Ayrıca bkz. ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 125. Aynı anlayış, CGK’nın, 9.10.2012 tarihli ve E. 2011/8-335, K. 2012/1804 sayılı Kararında da etkili olmuştur.

²⁰² ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 143, 145, 148. Yazara göre, “*pasif süje ve maddi konu sıfatları bazen aynı şahıs üzerinde toplanabilir. Bu olasılık, suçun ihlal ettiği hukuksal değerlerin sahibi ile suç teşkil eden eylem kendisine karşı işlenen kişinin aynı olması halinde ortaya çıkar.*” Tehdit ve hürriyeti tahdit gibi suçlar bu duruma örnek olarak gösterilmektedir (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 143). Ancak, yazar, “*mağdur ile suçun konusu(nun), adam öldürme suçunda olduğu gibi, aynı kişi olabilir*”eceği fikrindedir (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 144). *Erem/Danışman/Artuk* da bazı suçlar bakımından mağdur ile suçun konusunun birleştiğini kabul etmektedirler, Yazarlara göre, iftira suçunda bu iki kavram birbirinden ayrılırken, yaralama suçunda birleşmektedir (EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 242).

Suç teşkil eden fiilin ihlâl ettiği *hukuki değer* ile maddi unsurlardan birini oluşturan *suçun konusu* kavramları birbirine karıştırılmamalıdır.²⁰³ Meselâ, kasten veya taksirle öldürme suçunda ihlâl edilen hukuki değer, genel olarak kişinin *hayat hakkıdır, yaşama hakkıdır*. Buna karşılık, suçun konusu ise, belli bir *şahsın hayatıdır*. Kasten veya taksirle yaralama suçunda ihlâl edilen hukuki değer, genel olarak kişinin *vücut dokunulmazlığıdır*. Suçun konusu ise, belli bir *şahsın vücududur*.^{204, 205} Hakaret suçunun konusu, hakaret edilen *kişinin şerefidir*; bu suça ilişkin tanımla korunan hukuki değer ise, genel olarak *kişilerin şerefli, onurlu ve saygın olmasıdır*. Çevreyi kirletme suçlarının (m. 181, 182) konusu, çevreyi oluşturan *toprak, su ve havadır*. Buna karşılık, bu suçlarla korunan hukuki değer, *kişilerin sağlıklı, ekolojik dengesi bozulmamış bir çevrede yaşama hakkıdır*. Keza, TCK, m. 185’de tanımlanan zehirli madde katma suçunun konusu, *içilecek su, yenilecek ve içilecek her türlü besin, tüketilecek her çeşit maddenin yanı sıra, zehir katılan suyu, besini veya maddeyi tüketebilecek durumda olan kişilerin hayatı ve sağlığıdır*.²⁰⁶ Buna karşılık, korunan hukuki değer, *kişilerin sağlıklı yaşama hakkıdır*.

Korunan *hukuki değer*, suçun işlenmesiyle *ihlâl* edilmektedir. Buna karşılık, suçun işlenmesiyle, suçun *konusuna zarar* verilmekte veya *tehlikeye* maruz bırakılmaktadır.

A. Zarar Suçu - Tehlike Suçu Ayırımı

İşlenen fiilin suçun konusu üzerindeki etkisi itibarıyla, suçlar, *tehlike suçu* ve *zarar suçu* olarak ikiye ayrılmaktadır.

Zarar suçlarında, bizatihi haksızlık teşkil eden fiilin işlenmesi sonucunda suçun konusu üzerinde bir zarar meydana gelmektedir. Meselâ, mala zarar verme suçu (m. 151), bir zarar suçu niteliğindedir.

Mağdurun malvarlığında bir azalma meydana getiren suçlar da (m. 141 vd., 148, 149, 157, 158) zarar suçu niteliğindedir.

²⁰³ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 126, 142. Ancak, yazar, çalışmasının başka bir yerinde, bu görüşüyle çelişen açıklamalarda bulunmaktadır: “Bazen hukuksal değer ve hareketin objesi çakışır, aynı şey olurlar. Örneğin adam öldürme suçunda insanın yaşamı hem hukuksal değer hem de saldırının konusunu oluşturmaktadır.” (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 134).

²⁰⁴ Aynı mealde görüş için bkz. ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 50-52; ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 131, 133. Bu açıklamalarımız karşısında; *Dönmezer/Erman*’ın “hukuki değer” kavramıyla “suçun konusu” kavramına getirdiği ortak izaha (DÖNMEZER/ERMAN I, no. 470-471) katılmamaktayız. Artuk/Gökçen/Alşahin/Çakır, suçun konusu ile mağdurun birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirtmekle birlikte; yazarlara göre, kasten yaralama suçunda suçun konusu “*vücuduna acı verilen, sağlığı bozulan kişidir*” ve keza, hakaret suçunda “*suçun maddi konusu ise, onur, şeref ve saygınlığı rencide edilen kişidir*”: ARTUK/GÖKCEN/ ALŞAHİN/ÇAKIR, Genel Hükümler (13), sh. 379

²⁰⁵ *Erem*’e göre, kişinin kendi kendini itham suçunda (TCK., m. 283, f. 2) suçun faili aynı zamanda suçun konusunu oluşturmaktadır; mağdur ise, devlettir (EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 243).

²⁰⁶ ÜNAL, Osman Gazi: *Türk Ceza Hukukunda Tehlike Suçları*, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2020, sh. 141 vd.

İşaret etmek gerekir ki, burada söz konusu olan zarar, parasal bir ölçüme tabi tutulan (ekonomik) bir zarar değildir. Bu itibarla, meselâ, kasten veya taksirle öldürme ya da yaralama suçları da birer zarar suçu niteliği taşımaktadır²⁰⁷.

Her suç tanımının temelinde bir hukuki değer koruması yatar. Haksızlık, bir hukuki değeri ihlal eden fiili ve neticesini ifade eder. Başka bir ifadeyle, hukuki değer ihlalinin söz konusu olduğu hallerde mutlaka, fiil veya netice olarak bir haksızlık gerçekleşmiştir. Hukuki değerden farklı olarak suçun konusu zarara veya tehlikeye maruz bırakılır. Ceza hukukunda zarar, salt ekonomik zarar olarak anlaşılmamalıdır; suçun konusu bakımından bir değişiklik meydana gelmesini ifade etmektedir. Mala zarar verme suçunun konusunu oluşturan malvarlığı değerinin yapısında meydana gelen değişiklik, ekonomik bir zarar olarak ifade edilebilir²⁰⁸. Keza, mesela kasten yaralama suçu da bir zarar suçudur. Ancak bu suçun işlenmesiyle meydana gelen netice, ekonomik bir zararı ifade etmemektedir.

Zarar suçu nitelendirmesi, ancak neticenin arandığı suçlar bakımından yapılabilir. Buna karşılık, hakaret veya iftira gibi, fiilin işlenmesiyle tamamlanan, ayrıca bir neticenin gerçekleşmesinin aranmadığı suçlarla ilgili olarak, zarar suçu nitelendirmesi yapılamaz.

Tehlike suçlarında ise, icra edilen fiilin suçun konusu üzerinde bir *zarar* meydana getirme *tehlikesi* söz konusudur²⁰⁹. Tehlike suçları, kanun koyucunun bazı hukuki değerleri daha etkin bir şekilde korumak amacıyla, bunları ihlâl eden davranış dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için, herhangi bir zararın gerçekleşmesine gerek görmediği suçlardır²¹⁰.

B. Soyut Tehlike Suçu - Somut Tehlike Suçu Ayırımı

Tehlike suçları, *soyut ve somut tehlike suçları* olarak ikiye ayrılmaktadır.

Soyut tehlike suçlarında suçun kanunî tarifinde yer alan fiilin icra edilmesi yeterli olup, bunun dışında suçun konusu üzerinde gerçekten bir tehlikenin meydana gelip gelmediğinin araştırılıp tespit edilmesine gerek yoktur. Başka bir ifadeyle, kanun koyucu soyut tehlike suçlarında kanuni tarifteki hareketin yapılmasıyla suçun konusu bakımından bir tehlikenin ortaya çıkacağını varsay-

²⁰⁷ Kastan yaralama suçunda yaralama fiilinin icrası sonucunda kişinin psikolojisinin bozulması da bir neticedir (DEMİRTAŞ, Tehlike Suçları, 144).

²⁰⁸ Hırsızlık suçu da bir zarar suçudur. Zira, alma fiilinin icrasıyla, mağdurun malvarlığında bir eksilme, ve failin malvarlığında ise bir artma meydana gelmektedir (Bkz. DEMİRTAŞ, Tehlike Suçları, 145, 167).

²⁰⁹ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 59. İşaret etmek gerekir ki, ister zarar ister tehlike suçu olsun, bir suçun işlenmesi halinde ilgili hukuki değer ihlâl edilmektedir. Buna karşılık, zarar gören ya da tehlikeye maruz kalan, hukuki değer değil, suçun konusu ve dolayısıyla mağdurdur/mağdurlardır. Türk doktrininde bazı yazarlar bu ayrımı karıştırmıştır (DARAGENLİ, Erman'a Armağan, sh. 163; KANGAL, Zorunluluk Durumu, sh. 183).

²¹⁰ DARAGENLİ, Erman'a Armağan, sh. 183.

maktadır. Bu itibarla, soyut tehlike suçlarında hakim suçun konusu bakımından somut bir tehlikenin meydana gelip gelmediğini araştırmayacaktır²¹¹.

Meselâ, terk (m. 97), yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (m. 98), suç işlemeye alenen tahrik (m. 214), iftira (m. 267), yalan tanıklık (m. 272) ve yalan yere yemin (m. 275) suçları, birer soyut tehlike suçudurlar²¹².

Somut tehlike suçlarında ise, suçun kanunî tarifinde belirlenen fiilin icra edilmesinin yanı sıra, bu fiilin suçun konusu bakımından somut bir tehlike meydana getirip getirmediğinin, yani, gerçekten bir tehlikeye sebebiyet verip vermediğinin hakim tarafından araştırılıp tespit edilmesi gerekir. Bu araştırmanın, fiilin işlendiği şartlar nazara alınarak, yani ex ante bir değerlendirmeye yapılması gerekir²¹³. Ayrıca, gerçekleşen somut tehlike ile failin icra ettiği fiil arasında illiyet bağının da bulunması gerekmektedir²¹⁴ (m. 170, f. 1²¹⁵; m. 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179²¹⁶, 215, 216, 217, 220, 319).

Bu bakımdan, 765 sayılı Kanundaki düzenlemelerin aksine, yeni TCK'da, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (m. 216), kanunlara uymamaya tahrik (m. 217) ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma (m. 220) suçları *somut tehlike suçu* olarak tanımlanmıştır²¹⁷.

²¹¹ Demirtaş, bazı soyut tehlike suçlarında da dış dünyada bir değişikliğin ve neticenin meydana geldiğini savunur (DEMİRTAŞ, Tehlike suçları, sh. 143, 161, 165). Ancak, yazarın buna gösterdiği bir örnekle karşılaşmamıştır.

²¹² Ayrıca bkz. TCK, m. 170, f. 2; m. BAYRAKTAR, Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, sh. 69 vd., 128, 227; ÖNDER, Özel Hükümler(3), sh. 245; ÖNOK, Rıfat Murat: *TCK'da Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Suretiyle İşlenen Suçlar*, in: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Ocak 2012, sh. 31 vd.

²¹³ ÜNAL, Türk Ceza Hukuku'nda Tehlike Suçları, sh. 220 vd.

²¹⁴ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 61.

²¹⁵ Yargıtay, **Ceza Genel Kurulu**, şehir merkezinde seyreden aracın camından havaya ateş edilen "kurusıki" tabancanın ateşli silah niteliğinde olmadığı gerekçesiyle TCK'nın 170. maddesinde (f. 1, bent c) tanımlanan suçun oluşmadığı, Kabahatler Kanununun 36. maddesinde tanımlanan kabahatin oluştuğu içtihadında bulunmuştur: CGK, 3.7.2007, E: 2007/8-156, K. 2007/163. Ayrıca bkz. CGK, 3.7.2007, E: 2007/8-155, K. 2007/162; CGK, 3.7.2007, E: 2007/8-154, K. 2007/161; CGK, 3.7.2007, E: 2007/8-153, K. 2007/160; CGK, 26.6.2007, E: 2007/8-143, K. 2007/155; CGK, 29.5.2007, E: 2007/8-109, K. 2007/115. Hatta Yargıtay'a göre, yapılan atış "*korku, kaygı veya panik yaratabilecek nitelikte olsa dahi*" kurusıki tabanca "*silah sayılamayacağından*" TCK'nın 170. maddesinde tanımlanan suç oluşmaz: CGK, 12.6.2007, E: 2007/8-127, K. 2007/144; CGK, 12.6.2007, E: 2007/8-126, K. 2007/143.

²¹⁶ Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, bir somut tehlike suçudur. Ancak, Demirtaş, Türk Ceza Kanununda tanımlanan pek çok somut tehlike suçu gibi, bunun da soyut tehlike suçu olduğunu kabul etmektedir (DEMİRTAŞ, Tehlike Suçları, sh. 96/97, 199). Yazar, bu iddiada bulunurken Karayolları Trafik Kanunundaki düzenlemeleri ve özellikle 48. madde hükümlerini dikkate almamıştır.

²¹⁷ Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün silahlı olup olmaması veya sahip olunan silahların cins, nitelik ve miktarı bu somut tehlikenin tayininde dikkate alınmalıdır (ÖZGENÇ, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk, sh. 224, 227). Aynı doğrultuda görüş için bkz. MAHMUTOĞ-

Ancak, belirtelim ki, somut tehlike suçlarında, icra edilen kanunî tarife uygun fiilin suçun konusu açısından somut bir tehlike meydana getirmesi, bu suçlar açısından bir unsur olarak²¹⁸ değil, bir cezalandırılabilme şartı olarak anlaşılmalıdır. Kanımızca, bu tür suçlarda kanunî tarife uygun fiilin işlenmesiyle bir **haksızlık** gerçekleşmektedir. Bu itibarla, kanunî tarife uygun fiil, başlı başına bir haksızlık teşkil etmektedir. Bu haksızlığın oluşumu için gerçekleştirilen fiilin suçun konusu açısından somut bir tehlikeye sebebiyet vermesi gerekmez. Ancak, bu tür fiiller dolayısıyla ceza hukukunun müdahalesi, somut bir tehlikenin meydana gelmesi halinde mümkün olacaktır. Bu itibarla, **somut tehlikenin** oluşumu, söz konusu suçlar açısından bir **objektif cezalandırılabilme şartı** olarak anlaşılmalıdır^{219, 220}.

Keza, işaret edelim ki; bazı suçlar hem bir zarar suçu hem de bir tehlike suçu niteliği taşımaktadır. Kasten öldürme suçunun “*yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle*” işlenmesi (m. 82, f. 1, bent c) bu bakımdan örnek olarak gösterilebilir.

VI. Mağdur

A. Genel Olarak Mağdur Kavramı

Suçun maddi unsurlarından altıncısını, mağdur oluşturmaktadır. Suçun konusuyla *mağdur* kavramı da birbirine karıştırılmamalıdır. “Mağdur” kelimesi, “*kadre uğramış kişi*”, “*haksızlığa uğramış kişi*” anlamına gelmektedir. Suçun mağduru, suçun konusunun ait olduğu *kişidir*²²¹. Meselâ, hırsızlık suçunda suçun konusu çalınan eşyadır. Buna karşılık, suçun mağduru, bu malın sahibi olan, malın ait olduğu *kişidir*. Hayat hakkının veya vücut dokunulmazlığının ihlâl edildiği öldürme veya yaralama suçlarında da, pek belirgin olmamakla beraber, bu ayırım mevcuttur. Gerek öldürme gerek yaralama suçlarında suçun mağduru,

LU, Fatih Selami: *Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LXIII, yıl 2005, sayı 1-2, sh. 83.

²¹⁸ Gerçekleşen somut tehlikenin, suçun bir *unsuru* olduğu hususundaki görüş için bkz. LENCKNER, Schönke/Schröder(24), § 126, kn. 12; § 130, kn. 10; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 61; DARAGENLİ, Erman’a Armağan, sh. 184. Bu görüşe göre, somut tehlike, maddi unsur olarak, neticeyi oluşturur.

²¹⁹ ÖZGENÇ, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk, sh. 191; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ ÇAKIR, Genel Hükümler (13), sh. 381.

²²⁰ Somut tehlike suçlarında somut tehlike esasında bir neticedir ve suçun oluşabilmesi için bunun gerçekleşmesi gerekir. Ancak bunun suçun unsuru olan neticeden farkı, kast kapsamında değerlendirilmemesidir, yani bir objektif cezalandırılabilme şartı olmasıdır. Oysa yazar, somut tehlikeyi suçun bir unsuru olarak kabul etmektedir (DEMİRTAŞ, Tehlike Suçları, sh. 225, 258). Yazar, bu kabulüyle işlenen fiilin somut tehlikeye sebebiyet verip vermemesine göre suç veya kabahat oluşturabileceğini göz ardı etmiştir.

²²¹ Doktrinde bazı yazarlar mağdur kavramı karşılığında “suçun pasif süjesi” ibaresini kullanmaktadırlar: ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 140 vd.

tecavüze uğrayan *kişidir*. Buna karşılık, suçun konusu, öldürme suçunda, bu kişinin hayatı; yaralama suçunda ise, bu kişinin vücududur²²².

Suçun konusuna zarar verilmesi veya bunun zarar tehlikesine maruz bırakılması suretiyle, korunan hukuki değer ihlâl edilmiş olmaktadır²²³.

B. Mağdur - Suçtan Zarar Gören Ayırımı

Mağdur kavramı ile *suçtan zarar gören* kavramlarını da birbirine karıştırmamak gerekir²²⁴. Kural olarak, mağdur, aynı zamanda bir suçun işlenmesi dolayısıyla zarar gören kişidir. Meselâ, hırsızlık suçunun mağduru, aynı zamanda bu suçun işlenmesi dolayısıyla zarar gören kişidir. Fakat, suçtan zarar gören kişi, her zaman bu suçun işlenmesi dolayısıyla mağdur edilen kişi değildir²²⁵. Meselâ, bir kurumun parasına ve sair malvarlığına vaziyet eden bir görevliye cebir veya tehdit tatbiki suretiyle ya da hileye maruz bırakılmasıyla yağma (gasp) ya da dolandırıcılık suçu işlenmiş olabilir. Bu durumda, suçun mağduru, kendisine cebir veya tehdit tatbik edilen ya da hileye maruz bırakılan görevlidir. Buna karşılık, suçtan zarar gören, bu suretle malvarlığında azalma meydana gelen kurumdur^{226, 227}.

Mağdurun, hayatta olan bir insan olması gerekir. Ancak, belirtmek gerekir ki, işlenen suç dolayısıyla kişinin mağdur olabilmesi için, suç oluşturana *fiilin iş-*

²²² Doktrinde, bazı durumlarda suçun konusuyla mağdurun birleşebileceği görüşü benimsenmektedir (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1173; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 242; SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 225, 304).

²²³ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, sh.87 vd.

²²⁴ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1174.

²²⁵ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 144, 145.

²²⁶ Keza, adam öldürme suçunda mağdur öldürülen kişidir. Buna karşılık, suçtan zarar gören kişi, öldürülenin yakınlarıdır (DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1174; SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 223 vd., 225). Bu nedenledir ki, ceza muhakemesi hukukunda meselâ kamu davasına katılma (müdahale) yetkisi, *suçtan zarar gören kişiye* tanınmıştır (CMK., m. 365). Bu hususla ilgili olarak bkz. KUNTER/YENİSEY: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 11. bası, İstanbul, 2000, sh. 193; ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK: *Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku*, 5. bası, Ankara, 2000, sh. 269, 274 vd. TOSUN: *Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri*, cilt I, Genel kısım, 4. bası, İstanbul, 1984, sh. 206; EREM: *Di-yalektik Açıdan Ceza Yargılaması Hukuku*, 6. bası, Ankara, Kasım 1986, sh. 368; ROXIN, Claus, *Strafverfahrensrecht*, 20 Auflage, München, 1987, sh. 389 (§ 62); SCHROEDER, Friedrich-Christian: *Strafprozeßrecht*, München, 1993, sh. 209 vd., kn. 323 vd..

²²⁷ “Mağdur, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde, “*haksızlığa uğramış kişi*” olarak tanımlanmaktadır. Ceza hukukunda ise mağdur kavramı, suçun konusunun ait olduğu kişi ya da kişilerdir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun hazırlanmasında esas alınan suç teorisinde suçun maddi unsurları arasında yer alan mağdur, ancak gerçek bir kişi olabilecek, tüzel kişilerin suçtan zarar görmeleri mümkün ise de, bunlar mağdur olamayacaklardır. Suçtan zarar gören ile mağdur kavramları da aynı şeyi ifade etmemektedir. Mağdur suçun işlenmesiyle her zaman zarar görmekte ise de, suçtan zarar gören kişi her zaman suçun mağduru olmayabilir. Bazı suçlarda mağdur belli bir kişi olmayıp; toplumu oluşturan herkes (geniş anlamda mağdur) olabilecektir”: CGK, 13.6.2017, E. 2017/5-157, K. 2017/325; CGK, 6.6.2017, E. 2015/11.MD-1065, K. 2017/319.

lendiği sırada hayatta olması gerekir. Örneğin, kasten öldürme suçunun icra hareketlerinin gerçekleştirildiği sırada kişi hayattadır ve bu fiilin icrası sonucunda ölmektedir. Bu itibarla, fiilin icrası sırasında hayatta olduğu için, kasten öldürme suçunun mağduru, ölen kişidir. Buna karşılık, ölmüş olan bir kişinin üzerindeki eşyaların alınması suretiyle işlenen hırsızlık suçunda mağdur, ölen kişi değil, mirasçılardır. Çünkü, hırsızlık suçunun icra hareketlerinin gerçekleştirildiği sırada kişi hayatta değildir.

İşaret etmek gerekir ki, mağduru olmayan bir suç olmadığı gibi, bütün suçlarda mağdur ancak *gerçek kişiler*dir. Tüzel kişiler, bir suçun işlenmesi dolayısıyla zarar görmüş olabilirler; ancak, mağdur olamazlar^{228, 229}.

Bazı suçlar açısından mağdurun doğrudan doğruya devlet olduğu iddia edilmiştir²³⁰. Ancak, bu görüşe göre, devlet, “her suçun en üst, birinci derecede pasif süjesidir” yani mağdurdur²³¹. Keza, bu görüşe mensup yazarlarca, 765 s. TCK’nın İkinci Kitabının “Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler” başlığını taşıyan Birinci Babındaki, “Devlet idaresi Aleyhinde İşlenen Cürümler” başlıklı

²²⁸ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 141 vd. Aksi fikir için bkz. KUNTER, Suçun Maddi Unsurları, sh. 118; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1176; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 242; SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 224. Ancak Ünver çalışmasının başka bir yerinde, bu düşüncesiyle çelişen açıklamalarda bulunmaktadır: “... pasif süje yalnızca herhangi bir gerçek kişi, **tüzel kişi** ve tüzel kişiliği olmayan (toplum, aile gibi) kişi topluluğu olabilir.” (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 144, ayrıca sh. 148).

²²⁹ Buna rağmen Yargıtay, dolandırıcılık suçu bağlamında şirketlerin de “mağdur” olarak kabulü yönünde içtihatla bulunmuştur: **CGK, 9.3.2010**, E. 2009/11-109, K. 2010/48.

²³⁰ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1175, 1178; SOYASLAN, Doğan: *Ceza Hukuku Özel Hükümler*, 3. bası, Ankara, 1999, sh. 25, “Devletin emniyetine karşı suçlarda suç mağduru devletin bizzat kendisidir”: sh. 37.

Anayasa Mahkemesinin bir kararında, bu düşüncelerin etkisiyle, **mağdur ile suçtan zarar gören kavramları arasındaki ayırmadan habersiz** olarak, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin de suçun “mağduru” olabileceği yönünde açıklamalara yer verilmiştir:

“Kamu tüzel kişilerinin bir suçun faili olup olamayacakları konusunda öğretide tartışmalar olsa da, **başta devlet olmak üzere diğer kamu tüzel kişilerinin bir suçun mağduru olma konumları tartışmasıdır**. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin suçtan zarar gören konumda olabilecekleri Türk ceza hukukunda da kabul edildiği için, hem ceza kanunlarında hem de suç ve ceza hükmü içeren özel kanunlarda bunlarla ilgili suç kategorileri hep var olmuştur. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan devletin şahsiyetine karşı cürümler ve devlet idaresi aleyhinde işlenen cürümler bu kapsamda sayılabilir. Aynı şekilde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda millete ve devlete karşı suçların, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçların, devletin güvenliğine karşı suçların, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçların ve milli savunmaya karşı suçların düzenlenmesi, **devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin suçtan zarar gören** konumunda olduklarına, ayrıca gerçek kişilerden ve özel hukuk tüzel kişilerinden farklı şekilde korunduklarına ilişkin düzenlemelere örnek gösterilebilir.” (Any. Mahk., 5.3.2009, E. 2006/77, K. 2009/39, RG: 27 Mart 2010/27534).

²³¹ SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 37. Ayrıca bkz. aynı yazar, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 224; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1172; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 242.

Üçüncü Babındaki ve “*Adliye Aleyhinde Cürümler*” başlıklı Dördüncü Babındaki suçların mağdurunun “devlet” olduğu kabul edilmiştir²³².

Devletin suçun mağduru olabileceği görüşü, devleti bir hak süjesi olarak kabul eden eski anlayışın bir ürünüdür²³³. Halbuki, hak süjesi, ancak bireylerdir. Devlete haklar ve yararlar izafe eden anlayış, Batıdaki faşizm ve nazizm düşüncelerinin hukuka yansımış tezahürleridir²³⁴.

Bazı suçlarda mağdur, muayyen kişi veya kişilerdir. Meselâ, öldürme veya yaralama suçlarında mağdur, öldürülen veya yaralanan kişidir. Hırsızlık, yağma veya dolandırıcılık suçlarında, malı alınan, malı gasbedilen veya dolandırılan kişi(ler) mağdur edilmektedirler.

Ancak, bütün suçlarda, aynı zamanda toplumu oluşturan ve barış esasına dayalı bir Hukuk Toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes mağdur olmaktadır (geniş anlamda mağdur kavramı). Meselâ, TCK’nın “*Genel Tehlike Yaratan Suçlar*” (m. 170 vd.), “*Çevreye Karşı Suçlar*” (m. 181 vd.), “*Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar*” (m. 185 vd.), “*Kamu Güvenine Karşı Suçlar*” (m. 197 vd.), “*Kamu Barışına Karşı Suçlar*” (m. 213 vd.), “*Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar*” (m. 235 vd.), “*Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar*” (m. 247 vd.), “*Adliye Karşı Suçlar*” (m. 267 vd.), “*Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar*” (m. 302 vd.) başlıklı Bölümlerde yer alan pek çok suçun muayyen bir kişi olarak mağdurundan söz edilemez. Bu suçların işlenmesiyle, toplumu oluşturan ve barış esasına dayalı bir Hukuk Toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, mağdur edilmektedir.

Bazı suçlarda toplumu oluşturan herkes mağdur olduğu gibi (geniş anlamda mağdur), muayyen kişi veya kişiler de mağdur edilmektedir. Meselâ, iftira (m. 267) veya yalan tanıklık (m. 272) suçlarında, toplumu oluşturan herkesin yanı sıra, kendisine iftira edilen ya da aleyhine yalan şahitlikte bulunulan kişi de mağdur edilmektedir (dar anlamda mağdur kavramı)²³⁵.

Suç tanımında mağdur olan kişide insan olmanın dışında başka özel nitelikler de aranabilir. Örneğin, mağdurun “*kamu görevlisi*” (m. 86, f. 3, bent g; m. 125, f. 3, bent a) “*çocuk*” (m. 82, f. 3, bent e); m. 94, f. 2, bent a), “*yargı görevini yapan*” (m.

²³² SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 225.

²³³ “Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhinde Cürümler” başlıklı Doçentlik Tezinin hazırlanmasında tamamen bu görüşün etkisinde kalan Özek’e göre, “hukukun gayesi, devletin varlığını ve devamını korumak”tır (ÖZEK, Çetin: *Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhinde Cürümler*, İstanbul 1967, sh. 38).

²³⁴ ÖZEK Çetin: *1997 Türk Ceza Yasa Tasarısı’na İlişkin Düşünceler*, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan’dan Ayrı Bası, İstanbul 1999, sh. 27 vd.

²³⁵ Erem’e göre, iftira suçunda kendisine iftira edilen kişi, mağdur değil, suçtan zarar gören kişidir (EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 285).

265, f. 2) veya faille belli akrabalık ilişkisi içinde bulunan kimse (m. 82, f. 1, bent d; m. 86, f. 3, bent a; m. 102, f. 3, bent c; m. 103, f. 3, bent c) olması gibi²³⁶.

VII. Suçun Nitelikli Unsurları

Kanunda önce bir *suçun temel şekli* tanımlanmaktadır. Meselâ, “*Bir insanı kasten öldüren kişi, ... cezalandırılır.*” (m. 81). “*Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye ... hapis cezası verilir.*” (m. 141).

Kanunda ayrıca, suçun bu temel şekline nazaran cezanın artırılmasını veya azaltılmasını gerektiren unsurlara da yer verilmektedir. Biz, bu unsurları *nitelikli (mevsuf) unsurlar* olarak isimlendirmekteyiz²³⁷. 765 s. Kanunun sisteminde, klasik ceza hukuku anlayışının bir sonucu olarak, bu unsurlara “*ağırlatıcı sebepler*” ve “*hafifletici sebepler*” denmektedir. Doktrinde, faile verilecek cezanın artırılmasını veya eksiltilmesini sağlamanın dışında bu nedenlerin hukuki niteliği üzerinde durulmamıştır. Bu nedenledir ki; meselâ haksız tahrik hali²³⁸ ve faal nedamet²³⁹, birer “hafifletici sebep” olarak kabul edilmiştir. Yeni TCK sisteminde “ağırlatıcı sebep” ve “hafifletici sebep” kavramları kullanılmamıştır²⁴⁰.

Suçun bu nitelikli unsurlarını şu şekilde bir tasnife tabi tutabiliriz²⁴¹:

a) ***Fülin işleniş tarzı itibarıyla nitelikli unsurlar.*** Meselâ, kasten öldürme suçunun “*canavarca hisle veya eziyet çektirerek*” (m. 82, f. 1, bent b), “*yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle*” (m. 82, f. 1, bent c) işlenmesi; keza, kasten yaralama (m. 86, f. 3, bent e) veya yağma (m. 149, f. 1, bent a) suçunun *silahla* işlenmesi, kişinin suçun temel şekline nazaran daha ağır bir ceza ile cezalandırılmasını gerektirmektedir.

²³⁶ Yargıtay **Ceza Genel Kurulunun** bir kararında, mağdur ve suçtan zarar gören kavramları arasındaki ilişki ve farklar bağlamında yer verilen genel açıklamalar doğru olmakla birlikte, bu açıklamalarla bağdaşmayan bir sonuca varılmış ve bir banka görevlisi tarafından işlenen zimmet suçunda banka tüzel kişiliğinin suçun “mağdur”u olduğu kabul edilmiştir (16.12.2008, E. 2008/5-146, K. 2008/235).

²³⁷ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 89.

²³⁸ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1087.

²³⁹ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1277.

²⁴⁰ Bunun tek istisnasını, “bileşik suç”a ilişkin 42. madde hükmü oluşturmaktadır. Bu madde metninde “ağırlatıcı neden” ibaresi kullanılmıştır. Aslında biz, yeni TCK’ya ilişkin olarak TBMM Adalet Komisyonunda yapılan çalışmalar sırasında, bu maddenin bütünüyle Tasarı metninden çıkarılmasını önermiştik. Ancak, bu önerimiz kabul edilmeyerek, söz konusu madde Hükümet Tasarısında (m. 54) olduğu şekliyle muhafaza edilmiştir.

²⁴¹ Bu bağlamda aşağıda yapmış bulunduğumuz tasnifi esas alan açıklamalar için bkz. ERDAĞ, Netice Sebebiyle Ağırlanmış Suç, sh. 81 vd.; DEMİRTAŞ, Soner: *Suçun Nitelikli Hallerine Teşebbüs*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXV, yıl 2021, sayı 3, 382 vd.

Keza, hırsızlık suçunun “kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak” (m. 142, f. 2, bent a), “elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle” (m. 142, f. 2, bent b), “doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak” (m. 142, f. 2, bent c), “haksız yere elde bulundurulmuş veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle” (m. 142, f. 2, bent d), “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle” (m. 142, f. 2, bent e), “tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak” (m. 142, f. 2, bent f); yağma suçunun “kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle” (m. 149, f. 1, bent b) işlenmesi, bu suç açısından faile daha ağır bir cezanın verilmesini gerektiren bir *nitelikli unsur* oluşturmaktadır.

Bazı suçlarda *aleniyet*, suçun temel şekline ilişkin bir unsur niteliğindedir (m. 132, f. 3; m. 190, f. 2; m. 213, f. 1; m. 214, f. 1; m. 215, m. 216, f. 1, 2, 3; m. 217; m. 225; m. 226, f. 1, bent b; m. 264, f. 1; m. 285, f. 3; m. 288; m. 300, f. 1, 2; m. 301, f. 1, 2). Buna karşılık, bazı suçlarda aleniyet, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurunu oluşturmaktadır (m. 125, f. 4; m. 130, f. 1; m. 299, f. 2).

b) ***Fiilin işlendiği yer veya zaman itibarıyla nitelikli unsur.*** Bazı suçlarda, suçun örneğin *gece vakti* işlenmesi, temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir (konut dokunulmazlığının ihlali suçu açısından, m. 116, f. 4; hırsızlık suçu açısından, m. 143; yağma suçu açısından, m. 149, f. 1, bent h).

Yağma suçunun “*konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde*” (m. 149, f. 1, bent d) işlenmesi veya hırsızlık suçunun belirli yerlerde bulunan eşya hakkında işlenmesi, bu suçlar açısından daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak tanımlanmıştır.

c) ***Failin vasfı itibarıyla nitelikli unsurlar.*** Bazı suçlarda, suçun temel şekli herkes tarafından işlenebilirken, nitelikli şekli ancak belli özel faillik vasfını taşıyan kişi tarafından işlenebilir (*görünüşte özgü suçlar*)²⁴². Meselâ resmî belgede sahtecilik suçunun *kamu görevlisi* tarafından işlenmesi halinde, fail suçun temel şekline nazaran daha ağır bir ceza ile cezalandırılmaktadır (m. 204, f. 1, 2). Cinsel saldırı veya çocukların cinsel istismarı suçunun *kamu görevlisi* tarafından “görevinin ... sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle” işlenmesi (m. 102, f. 3, bent b; m. 103, f. 3, bent e), bu hususta diğer bir örneği oluşturmaktadır.

d) ***Mağdurun vasfı itibarıyla nitelikli unsurlar.*** Meselâ, kasten öldürme suçunun *kamu görevlisine* karşı görevi dolayısıyla işlenmesi halinde (m. 82, f. 1, bent g), faile suçun temel şekline nazaran daha ağır bir ceza verilmektedir. İşkence suçunun “*avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla*”

²⁴² Kur'an'da, **failin sıfatının**, bazı durumlarda suçun **daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsuru** olduğuna, keza bazı durumlarda, suçun **daha az cezayı gerektiren bir nitelikli unsuru** olduğuna işaret edilmiştir (Birinci durumla ilgili olarak Ahzâb [33], Ayet 30; ayrıca bkz. Ayet 68; Tevbe [9], Ayet 101. İkinci durumla ilgili olarak Nisâ' [4], Ayet 25).

işlenmesi de bu suç açısından nitelikli bir unsurdur (m. 94, f. 2, bent b). Keza, bir kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret edilmesi, bu suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir (m. 125, f. 3, bent a). Cumhurbaşkanına hakaret, genel hakaret suçuna nazaran daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır (m. 299).

e) **Fail ile mağdur arasındaki ilişki itibarıyla nitelikli unsurlar.** Meselâ, fail ile mağdur arasındaki belli akrabalık ilişkisi, kasten öldürme (m. 82, f. 1, bent d) ve kasten yaralama (m. 86, f. 3 bent a) suçlarının bir nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçunun “*üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından*” ya da “*vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından*” işlenmesi, daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsur oluşturmaktadır (m. 103, f. 3, bent c, d).

f) **Suçun konusu itibarıyla nitelikli unsurlar.** Meselâ, hırsızlık suçunun, “*kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında*” (m. 142, f. 1, bent a), “*herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında*” (m. 142, f. 2, bent h), “*halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında*” (m. 142, f. 1, bent c), “*bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında*” (m. 142, f. 1, bent d), “*adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında*” (m. 142, f. 1, bent e), “*büyük veya küçük baş hayvan hakkında*” (m. 142, f. 2, bent g) işlenmesi, bu suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Buna karşılık, hırsızlık suçunun “*paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde*” işlenmesi halinde, faile daha az cezayı gerektiren bir nitelikli unsur söz konusudur (m. 144, f. 1, bent a).

Bazı suçlarda, konunun değerinin azlığı, suçun temel şekline nazaran daha az ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Örneğin, “*yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.*” (m. 150, f. 2)²⁴³. Hatta, “*hırsızlık suçunun konusunu oluşturan*

²⁴³ TCK’nın 150. maddesinin ikinci fıkrası, “yağma suçunun konusunu oluşturan değer az olmasını temel almaktadır. Değer azlığı ile kanun koyucu tarafından neyin kastedildiği, tereddütleri önleyecek biçimde açıklığa kavuşturulmamış, rakamsal bir sınırlandırma getirilmemiş fakat hakime, yargılama konusu maddi olayla ilgili olarak takdir ve değerlendirme yetkisi tanınmıştır. Hakim, gasp edilen veya gasp edilmeye kalkışılan şeyin değerinin azlığını ceza indirimi yaparak değerlendirebilecektir.

5237 sayılı Kanunun 150. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında, 765 sayılı TCK’nın 522. maddesinde öngörülen “hafif” ya da “pek hafif” kavramlarıyla irtibatlı bir yoruma giril-

ran malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” (m. 145).

g) **Fiilin işlenişiyile güdülen amaç veya saik itibarıyla nitelikli unsurlar.** Meselâ, kasten öldürme suçunun “*bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla*” (m. 82, f. 1, bent h), “*kan gütme saikiyle*” (m. 82, f. 1, bent i) veya “*töre saikiyle*” (m. 82, f. 1, bent j) işlenmesi, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurunu oluşturmaktadır.

Yeni TCK’nın sisteminde “ihkakı hak” (kendiliğinden hak alma) (765 s. TCK, m. 308) olarak bir suç tanımına yer verilmemiştir. Ancak, örneğin hırsızlık suçunun “*bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla*” işlenmesi (m. 144, f. 1, bent b), temel şekline nazaran daha az cezayı gerektiren nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Keza, “*dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi*”, bu suçun temel şekline nazaran daha az ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Aynı şekilde, “*bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, ... indirilir.*” (m. 211). Buna karşılık, “*kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması hâlinde*”, yağma suçundan dolayı değil, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır (m. 150, f. 1)²⁴⁴.

memeli, Yargıtay’dan anılan maddenin uygulanması sürecindeki içtihatlarına paralel şekilde yıllık değer ölçülerini belirlemesi beklenmemelidir.

Hâkim, bu değerlendirmenin yanı sıra her somut olayda, olayın özelliklerini dikkate alacak, 5237 sayılı TCK’nın 3. maddesinde öngörüldüğü üzere “*işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı*” olacak şekilde ceza adaletini sağlayacaktır. Görüldüğü gibi, madde ile getirilen sistem, **sadece malın değerinin objektif ölçütlere göre belirlenerek cezadan indirim yapılmasından ibaret değildir. Olayın özelliği her somut olayda değerlendirmeye konu edilecek**, meydana gelen haksızlığa faili iten etkenler ve bu haksızlığın mağdur üzerindeki etkileri de gözetilerek, **indirim yapıp yapmama konusunda takdir kullanılacak** ve maddenin uygulanıp uygulanmamasına ilişkin gerekçe kararda gösterilecektir.

Buna karşılık maddenin uygulanmasındaki en önemli ölçüt, şüphesiz değer ölçüsüdür. Ölçüye konu edilmesi gereken değer ise, fiilen gasp edilen olmayıp, eylem kastına dahil edilen olmalıdır. Bu değer ise “*indirim yapılmasını*” haklı kabul ettirecek düzeyde az olması gerekmektedir.

Bu açıklamalar ışığında uyumsuzluk konusu değerlendirildiğinde; sanığın mağdurenin evinin önüne gelip kapıyı yumruklayarak ve pencere camını kırarak zorla 20 TL para istediği anlaşılan olayda; gasp edilmek istenen para miktarının cezadan indirim yapılmasını haklı kabul ettirecek düzeyde az olduğu, olay tarihi itibarıyla sabıkasız olup aldığı aşırı alkollün tesiri ile hareket ettiği anlaşılan sanığın mağdureye ait ne varsa alma kastı ile hareket etmeyip sadece sigara ve alkol almak için az bir para istemekle iktifa ettiği hususları hak ve nasafet kuralları ile birlikte göz önüne alındığında, sanık hakkında 5237 s. TCK’nın 150. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanma şartlarının bulunduğu kabul edilmelidir.”: CGK, **24.2.2015, E. 2013/6-817, K. 2015/14.**

²⁴⁴ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **4.12.2012** tarihli ve E. 2012/6-1247, K. 2012/1842 sayılı kararında bu bağlamda yer alan açıklamalar önem taşımaktadır:

“765 sayılı Kanunun sisteminde, suçun temel şekline göre cezanın artırılmasını veya azaltılmasını gerektiren hususlara “*ağırlaştırıcı sebepler*” ve “*hafifletici sebepler*” denilmekte iken

§15. Suçun Manevi Unsuru

Suçun diğer bir unsuru da, manevi unsurdur. Manevi unsur, işlenen fiil ile kişi arasındaki *manevi bağı* ifade etmektedir. Bu bağ tesis edilmeden, gerçekleştirilen davranış fiil niteliğini taşımaz ve dolayısıyla, bir suçun varlığından söz edilemez.

Ancak, belirtmek gerekir ki, manevi unsurla kusurluluğu da birbirine karıştırmamak gerekir. Bilahare izah edileceği gibi, kusurluluk, işlediği suç dolayısıyla kişinin kınanması, muaheze edilmesi gerektiği hususundaki *yargıyı* ifade etmektedir. Bu bakımdan kusurluluk, işlediği fiille irtibatlı olarak kişi açısından bulunulan bir değerlendirme yargısıdır ve dolayısıyla, suçun bir unsurunu oluşturmaz. Başka bir deyişle, kişi işlediği fiilden dolayı kusurlu bulunmasa bile, bu fiil suç olma özelliğini muhafaza eder. Buna karşılık, kanunî tanımda aranan manevi unsur gerçekleşmediği takdirde, suç oluşturan bir haksızlığın varlığına

5237 sayılı Kanunda, suçun temel şekline göre cezanın artırılmasını veya azaltılmasını gerektiren nedenler nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Bunun sonucu olarak da nitelikli haller yalnızca daha ağır cezayı veya cezada artırımı gerektirmemekte, kanunda daha az cezayı gerektiren nitelikli haller de yer almaktadır.

Nitekim bir suça ilişkin olarak hem daha ağır hem de daha az ceza verilmesini gerektiren hallerin gerçekleştiği ahvalde TCK'nın 61/4 maddesinde; "*Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla nitelikli hâllerin gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce artırma sonra indirme yapılır*"denilmek suretiyle, daha az cezayı gerektiren hallerin de nitelikli hal olarak kabul edildiği açıkça vurgulanmıştır. Bu kapsamda, TCK'nın 146. maddesinde, (hırsızlık suçunun) malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi, 150. maddesinde, yağma suçlarının bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi, daha az cezayı gerektiren nitelikli haller olarak düzenlenmiştir. Öğretide nitelikli haller; fiilin işleniş tarzı, fiilin işlendiği yer ve zaman, failin sıfatı, mağdurun sıfatı, fail ile mağdur arasındaki ilişki, suçun konusu, fiilin işlenmesinde güdülen amaç gözönüne alınarak sınıflandırılmaktadır.

5237 sayılı TCK'nın bazı maddelerinde suçun nitelikli hali için, bağımsız yaptırım öngörülmüş iken (örneğin; 94/2-3, 102/2, 103/2, 106/2, 109/2, 149/1. maddeleri), bazı maddelerinde suçun temel şekli için belirlenen cezanın belli oranlarda artırılması yöntemi tercih edilmiş (örneğin; 86/3, 102/3, 103/3-4, 109/3. maddeleri) bazı maddelerinde ise suçun nitelikli halleri için hem bağımsız bir ceza öngörülmüş (örneğin; 102/2, 103/2, 109/2. maddeleri), hem de aynı maddenin müteakip fıkralarında yer alan nitelikli haller için cezanın belirli bir oranda artırılması esası kabul edilmiştir. (örneğin; 102/3, 103/3-4, 109/3. maddeleri)

Kanunda, suçun nitelikli halleri için bazı maddelerde bağımsız bir ceza öngörülmesi, bazı maddelerde ise cezanın belirli bir oranda artırılması esasının kabulü, uygulamada birtakım zorluklara neden olsa da, bu tercih bütünüyle kanun koyucunun takdiridir. Bununla birlikte bu takdir, kanunda cezanın belirli bir oranda artırılmasının öngörüldüğü hallerin nitelikli hal olmayıp ağırlaştırıcı neden olduğu anlamına da gelmemektedir. Kanun koyucunun bu tercihi, benzer konularda farklı bir uygulamaya ve bu bağlamda adaletsiz sonuçların doğmasına yol açmamalıdır. Bağımsız yaptırım öngören nitelikli haller yönünden, nitelikli halin cezasının üst sınırının dikkate alınması, buna karşın belirli bir oranda artırım öngören maddelerde ise bağımsız ceza öngörülmemesi nedeniyle nitelikli hal olmadığı kabul edilerek bu artırımın dikkate alınmaksızın suçun temel şeklinin cezasının nazara alınması eşitsizlik ve adaletsizliğe yol açabilecektir. Nitekim Ceza Genel Kurulunun 30.03.2010 gün ve 43-71 sayılı kararında da benzer hususlara işaret edilmiştir."

dan söz edilemez. Bu itibarla, yeni TCK'ya hakim olan suç teorisinde, suçun manevi unsuru ile kusurluluk, birbirleriyle irtibatlı ve fakat, içerik ve fonksiyonları bakımından birbirinden ayrı kavramlar olarak anlaşılmalıdır.

Suçun manevi unsuru olarak ilk akla gelen, *kast* ve *taksir*dir.

I. Kast

A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Kast ve Kusurlulukla İlişkisi

Sorumluluğun temel şartı, insan davranışının iradî olarak gerçekleştirilmesidir. Bu itibarla, insan, iradî olarak gerçekleştirmediği fiil hukuka aykırı olsa bile, bu fiilden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. İşlediği fiil ile kişi arasındaki bağlantı, suç teşkil eden haksızlığın *manevi unsurunu* oluşturmaktadır.

Haksızlık teşkil eden bir fiilin işlenmesi halinde, bu haksızlığı gerçekleştiren kişinin şahsi özelliklerini dikkate almaksızın, bu fiil hakkında bir değerlendirilmede bulunmaktadır. Buna karşılık, kusurluluk söz konusu olduğunda; gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla, bir insan olarak faili hangi şartlarda sorumlu tutabileceğimiz tetkik konusu edilmektedir. Bu konuda bir yargıya varabilmek için, işlenen fiilin (haksızlığın) hangi şartlarda gerçekleştirildiğinin araştırılması gerekir. Kısaca kusurluluk, gerçekleştirdiği haksızlıkla ilgili olarak faildeki *iradenin oluşum şartlarının*²⁴⁵ tespiti ve bu tespiti binaen gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla failin şahsen muaheze edilmesi gerekip gerekmediği hususundaki yargıyı ifade etmektedir²⁴⁶.

Kusurluluk, suç teşkil eden fiilin bir vasfı değildir. Kusurluluk, haksızlık teşkil eden fiili gerçekleştiren şahsın bu fiili gerçekleştirmesi nedeniyle muaheze edilmesi gerektiği konusundaki yargıyı ifade etmektedir. Bu itibarla, kusurluluk, işlediği haksızlıkla ilgili olarak fail hakkında bulunulan yargıdan ibarettir²⁴⁷. Kusurluluk, belli bir fiile ilişkin olarak fail hakkındaki yargı olduğuna göre; belli bir fiilden soyut olarak, kişinin sürdürdüğü hayat tarzı itibarıyla kusurlu²⁴⁸ olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Ancak, kişinin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar, gördüğü eğitim gibi hususların, işlediği fiile ilişkin kusurunun belirlenmesinde etkili olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Kusur, haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi hakkında bir muaheze yargısı olması nedeniyle; bir fiil, failinin kusuru olmadan işlense dahi, haksızlık ve dolayısıyla, suç vasfını muhafaza edecektir. Demek ki, işlediği fiil dolayısıyla failin kusurlu addedilmesi veya addedilememesi, bu fiilin suç vasfını haiz bir haksızlık olması üzerinde etki doğurmayacaktır. Bu itibarla, örneğin işlediği fiilin hukuki anlam muhtevasını

²⁴⁵ “Maximen der Willensbildung”.

²⁴⁶ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 363.

²⁴⁷ “Fiil ceza hukuku”.

²⁴⁸ “Fail ceza hukuku”.

kavrayamayacak derecede aklî bozuklukla malûl bir akıl hastasının bir insanı öldürmesi halinde, işlenen fiil bir suç teşkil etmektedir; ancak, failin kusur yeteneği olmadığı için, kusurundan bahsetmek mümkün olmayacaktır²⁴⁹. İşlenen fiil dolayısıyla failin kusurlu addedilmemesi halinde dahi; bu fiil, belirli bir haksızlık ifadesi edebileceğine göre, ceza hukuku açısından önem taşımaktadır. Ancak, bu durumda faile uygulanacak yaptırım farklılık arzedecektir. Şöyle ki; suç teşkil eden belli bir haksızlığın işlenmesinden dolayı failin kusurlu bulunulması halinde, uygulanacak yaptırım, bir cezadır. Buna karşılık; failin kusur ehliyetinin bulunmaması veya genel olarak kusursuz olması halinde dahi, işlenen fiil, suç (haksızlık) vasfını muhafaza edecektir. Ancak, bu durumda faile uygulanacak yaptırım, bir ceza değil, güvenlik tedbiri olacaktır^{250, 251}.

²⁴⁹ Ancak, ülkemizde ceza hukukçuları arasında klasik suç teorisi etkisini devam ettirdiği için; bazı yazarlar tarafından suç teşkil eden fiilin manevî unsuru ile kusur, aynı kavramlar olarak mütalâa edilmektedirler (bkz. KUNTER, Nurullah: *Suçun Kanunî Unsurları Nazariyesi*, İstanbul, 1949, sh. 90, 102; TOROSLU, Nevzat: *Ceza Hukuku*, 4. bası, Ankara, Ocak 1998, sh. 43, 101/102). Bu anlayışın sonucu olarak şu fikirler ileri sürülmüştür:

“... her fiil, muhakkak kusurlu fiildir. Kusursuz fiil diye bir şey, ... mevcut olamaz” (KUNTER, Nurullah: *Suçun Maddî Unsurları Nazariyesi (Hareket - Netice - Sebebiyet Alâkası)*, İstanbul, 1954, sh. 8). “Hareket, kusurluluktan, yani manevî unsurdan müstakil olarak derpiş edilemez” (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 52). “Kusurluluk olmadan hukuka aykırılık bahis mevzuu” edilemez (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 97, ayrıca sh. 99, 101, 102).

“Kusurluluğu kaldıran sebeplerin mevcudiyeti halinde suçtan bahsedilemez” (TOROSLU, Nevzat: *Ceza Hukukunda Zaruret Hali*, Ankara, 1968, sh. 50). “Hukuka aykırı olup da kusurlu olmayan bir davranış mevcut olamaz” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 70). “Hukuka aykırılık, kusurluluktan müstakil olarak tahakkuk edemez” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 71). “Kusurluluk mevcut değilse, hukuka aykırılıktan bahsedilemez” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 74). “Hukuka aykırılıktan bahsedebilmek için failin isnad kabiliyetini haiz olması ve kusurlu hareket etmiş bulunması şarttır. ... (C)ezaî ehliyetini kaybetmiş ... bir şahıs, suç işleyemeyeceği gibi, hukuken önemi haiz bir fiil de işleyemez” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 84, 117).

Yargıtay da çeşitli kararlarında bu görüşün etkisi altında kalmıştır:

“Çağdaş ceza hukukunda suçun asıl manevî unsurunu kusurluluk oluşturur.” CGK, 23.12.1985, 173/660 (Yaşar, Osman: *Uygulamada Türk Ceza Yasası*, Ankara, 2000, sh. 575/576).

²⁵⁰ KEÇELİOĞLU, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 87 (Mart – Nisan 2010), sh. 303 vd.

²⁵¹ Ancak, Öztürk, suç teşkil eden fiiller ve “suça benzeyen ve fakat teknik anlamda suç olarak nitelenmeyen emniyet tedbirlerini gerektiren fiiller” olmak üzere bir ayırım yapmaktadır. Öztürk’e göre; “esas yaptırımı emniyet tedbiri olan fiillerin, günümüz suç genel teorisi çerçevesinde suç olarak nitelendirilmesi mümkün değildir”. Çünkü, “Ceza normunu anlayamayan, anlayabildiği halde ona uygun hareket edemeyen bir kimsenin hareketi teknik anlamda suç olarak nitelenemez” (ÖZTÜRK, Bahri: *Ceza Muhakemesi Hukukunda Koğuşurma Mecburiyeti [Hazırlık Soruşturması]*, Ankara, 1991, sh. 3). Bu görüş, kanaatimizce, isabetli değildir. Çünkü, yukarıda da belirttiğimiz gibi, failin kusursuz olması halinde dahi işlenen fiil, suç (haksızlık) vasfını haiz olacaktır. Ancak, bu durumda faile tatbik edilecek müeyyide, ceza değil, tedbir olacaktır.

Belirtmek gerekir ki, Öztürk bu düşüncelerini halen sürdürmektedir (ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖZBEK, Veli Özer: *Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku*, 6. bası, Ankara 2002, sh. 99, 383 vd.).

İşlenen fiilin bir haksızlık teşkil ettiği yargısına varılması, aynı zamanda failin de muaheze edilmesi gerektiği yargısını ihtiva etmez. İşlenen bu haksızlık nedeniyle failin muaheze edilip edilemeyeceği yargısına bilahare ayrıca varılmaktadır (kusurluluk yargısı). İşlenen fiilin bir haksızlık teşkil ettiği konusundaki yargıya varırken, failin bu fiil karşısındaki manevi durumunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Yani, fail, prensip itibarıyla işlediği fiilin maddi unsurlarının şuurunda olmalıdır²⁵².

Kusur yargısından önce, kanundaki belirli suç tanımlarına uygun bir haksızlığın gerçekleştirilmesi gerekir. Bu haksızlık kasten işlenmiş veya taksirle gerçekleştirilmiş bir haksızlık olabilir. Böylece, kast ve taksir, birer kusurluluk şekilleri olarak değil; haksızlığın birer gerçekleştiriliş şekilleri olarak, kısaca, birer *haksızlık şekilleri* olarak anlaşılmaktadırlar²⁵³. Ancak, kusurluluğun, kast ve taksirden tamamen soyutlanarak, yalın bir değer yargısı olarak kabulü de söz konusu değildir²⁵⁴. Çünkü haksızlık, kusur yargısının dayanağını teşkil etmektedir; kusur yargısı, gerçekleştirilen bu haksızlık zemini üzerine bina edilmektedir. Haksızlık teşkil eden vakıa ile haksızlık yargısı arasında nasıl zorunlu bir ilişki mevcutsa; sorumluluk ve öncelikle kusur yargısıyla, bu yargının dayanağını teşkil eden haksızlık arasında da zorunlu bir bağlantı vardır. Böylece, haksızlığın bütün unsurları dolaylı bir şekilde kusurun belirlenmesinde de etkili olmaktadır. Kısacası, haksızlık, kusur yargısının dayanağını teşkil etmektedir, zeminini oluşturmaktadır²⁵⁵.

²⁵² Bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler (6), sh. 138 vd.; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, Genel Hükümler (13), sh. 434 vd.

²⁵³ Aksi görüş, kast ve taksiri birer yalın “kusurluluk şekli” olarak telâkki etmektedir (BAUMANN/WEBER, *Allgemeiner Teil*, 9. Auflage, sh. 430/431). Ancak belirtmek gerekir ki, *Baumann*’ın eserinin son basılarında kast ve taksir artık birer kusur şekli olarak anlaşılmadığı görüşüne yer verilmektedir (BAUMANN, Jürgen/WEBER, Ulrich//MITSCH, Wolfgang: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch*, 10. Auflage, Bielefeld, 1995, § 18, 25).

Türk Hukukunda halen kast ve taksirin, birer “kusurluluk şekli” veya “kusur türü” olduğu görüşü hakimdir: DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku*, Cilt II, 10. bası, İstanbul, Mayıs 1994, no. 917; İÇEL, Kayıhan: *Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk*, İstanbul, 1967, sh. 16 vd.; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 257; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 2. bası, sh. 229 vd.; EREM, Faruk: *Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, cilt I, 12. bası, 1984, sh. 504 vd.; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 443 vd.; SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 408 vd.; ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 6. bası, sh. 179 vd.; CENTEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 305 vd.; DEMİRBAŞ, Genel Hükümler, sh. 309 vd.; HAKERİ, Ceza Hukuku, 5. bası, sh. 215 vd.

²⁵⁴ Kusur, mutlaka bir haksızlıkla irtibatlandırılmalıdır. Bir başka ifadeyle, ancak bir haksızlığın gerçekleştirilmiş olması dolayısıyla kişi kusurlu addedilebilir. (SCHMIDHÄUSER, Eberhard: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch*, 2. Auflage, Tübingen, 1975, § 4, kn. 9; BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 23, kn. 5).

²⁵⁵ ROXIN, Claus: *Strafrecht - Allgemeiner Teil, Band: I, Grundlagen - Der Aufbau der Verbrechenstheorie*, 1. Auflage, München 1992, 2. Auflage, München 1994, § 10 kn. 68, 69, § 12

Kasten ve taksirle işlenen fiillerin mahiyetinde farklılıklar mevcuttur. Kasten işlenen haksızlıklar, birer ereksel (gaî) fiil olmaları itibarıyla, ontik bir mahiyet arz etmektedirler. Taksirli haksızlıklar ise, ontik vakıanın yanı sıra, mutlaka bir değerlendirme unsuru (objektif özen yükümlülüğünün ihlali) ihtiva etmektedirler. Kast ve taksiri birer kusurluluk şekli olarak kabul etmemekle beraber; kast ve taksirle işlenen haksızlıkların işlenişinde kusurun arz edeceği özelliklerin de birbirinden farklı olduklarını belirtmek gerekir.

Kast, kişi ile işlediği fiil ve neticesi arasında manevi bir bağ kurmaktadır. Kanunda suç olarak tarif edilmiş fiilin haksızlık teşkil ettiğine dair *unsurların* bilinmesi halinde; fiil kasten işlenmiştir²⁵⁶. Kast, bir *haksızlık unsuru* olarak tezahür etmektedir. “*Sübjektif haksızlık unsurları*”²⁵⁷ kavramının teorik olarak ortaya atılmasından sonra; özellikle gaî hareket teorisine mensup yazarlar tarafından haksızlık teşkil eden fiilin manevi unsurları “*şahsi haksızlık unsurları*”²⁵⁸ olarak mütalâa edilmişlerdir²⁵⁹. Bu itibarla, kast, gerçekleştirilen haksızlığın manevi unsuru olarak kabul edilmekle beraber; aynı zamanda kusur yargısının zeminini oluşturmaktadır²⁶⁰.

kn. 26 ve özellikle § 19 kn.14-15. JAKOBS, Günther: *Strafrecht, Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre*, Berlin/New York, 1983, § 17, kn. 44; ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet/ŞAHİN, Cumhur: *Uygulamalı Ceza Hukuku*, Ankara, 2001, sh. 76 vd.; 147 vd., 228 vd.

²⁵⁶ Yargıtay kararlarında kasdın çeşitli tanımlarına rastlamaktayız: “*Kast, hareket ve netice ile fail arasındaki ruhi bağdır*”: CGK., 27.1.1984, 6-360/32 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1085 vd. [1089]). “*Kast, (failin) iradesinin kanunun suç saydığı fiile yönelmesidir*”: CGK., 29.11.1982, 5-383/457 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, birinci bası, sh. 1147).

²⁵⁷ Subjektive Unrechtselemente (MEZGER, Edmund: *Die subjektiven Unrechtselemente*, in: GS 89 [1924], sh. 207 vd. [245 vd.]). Kavram hakkında bilgi için Türkçe kaynak olarak bkz. KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 54 vd. Kusur ile manevî unsur arasındaki farka ilişkin açıklamaları sağlam bir teorik temele dayanmadığı için; *Kunter*’in bu kavrama ilişkin eleştirisini (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 58 vd.) doğru bulmamaktayız.

²⁵⁸ Personale Unrechtselemente.

²⁵⁹ WELZEL, Hans: *Um die Finale Handlungslehre*, 1949, sh. 7 vd.; WELZEL, Hans: *Das neue Bild des Strafrechts*, 4. Auflage, Göttingen, 1961, sh. 29; WELZEL, Hans: *Das deutsche Strafrecht* (Lehrbuch), 11. Auflage, Berlin, 1969, sh. 60 vd.; NIESE, Werner: *Finalitaet, Vorsatz und Fahrlaessigkeit*, Tübingen, 1951, sh. 11; *SYSTEMATISCHER KOMMENTAR zum Strafgesetzbuch* (RUDOLPHI, Hans Joachim/HORN, Eckhard/SAMSON, Erich/GÜNTHER, Hans-Ludwig), 6. Auflage, Berlin, März, 1995, vor § 32, kn. 4 vd.; MAURACH, Reinhart/ZIPF, Heinz: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband I*, 7. Auflage, Heidelberg, 1987, sh. 327/328; STRATENWERTH, Günter: *Strafrecht, Allgemeiner Teil I. Die Straftat*, 3. Auflage, Köln/Berlin/Bonn, 1981, kn. 186 .

²⁶⁰ RUDOLPHI, Systematischer Kommentar, § 16, kn. 3. *Dohna*’nın “değerlendirmenin objesi” ve “objenin değerlendirilmesi” kavramlarına ilişkin izahı (GRAF ZU DOHNA, Alexander: *Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 4. Auflage, Bonn, 1950, sh. 2, 19.), kast ile kusur arasındaki ilişkiyi daha iyi açıklamaktadır. Şöyle ki; meselâ bir hırsızlık suçunda failin kastı, hukuken olumsuz bir değer taşımaktadır. Hırsızlık kastı, bu durumda kusuru oluşturmamakta; aksine değerlendirmenin konusunu oluşturmaktadır. Böylece, kastın kusur kapsamında mütalâa edilmemesi gerektiği ve kusurun da sadece bir değerlendirmeden ibaret olduğu anlaşılmış olmaktadır.

Kast için önemli olan, belli bir amaca yönelik olarak kişinin davranışlarını yönlendirmesidir. Fakat, bu yönlendirmenin serbest iradeye dayanması ve bu nedenle kişinin muaheze edilebilmesi, kastın varlığı için gerekli değildir. Bu itibarla, yaş küçüğü, akıl hastası veya sarhoş olan bir kişi dahi kasten hareket edebilir²⁶¹.

Suçun kanunî tarifinde yer alan *bütün maddi unsurlar*, kast kapsamına dahildir. Suçun haksızlık muhtevasını belirleyen unsurlar²⁶² fail tarafından bilinmeli ki, kastının varlığından bahsedilebilsin. Failin bilmesi gereken bu unsurlar, geçmişte²⁶³ veya halen²⁶⁴ mevcut olan bir hususa ilişkin olabileceği gibi, ileride gerçekleşecek bir hususa da ilişkin olabilir. Bu itibarla; işlenen fiilin sebebiyet verdiği ve kanunî tarifte yer alan *neticenin* bilinmesi de, kastın varlığı açısından gereklidir^{265, 266}. Bu itibarla, meselâ aldığı eşyanın başkasına ait olduğunu bilmeyen kimsede hırsızlık kastı bulunmamaktadır. Belli bir eşyayı hırsızlık ürünü olduğunu bilmeden satın alan kişide, TCK, m. 165’de tanımlanan suça ilişkin kast bulunmamaktadır²⁶⁷. Keza, girdiği binanın mesken olduğunu bilmeyen veya

²⁶¹ RUDOLPHI, Systematischer Kommentar, § 16, kn. 5. Bir çocuğun veya bir akıl hastasının davranış normlarına aykırı davranışı da, bir haksızlık teşkil edebilir (SCHMIDHAEUSER, Lehrbuch, §4, kn.4).

²⁶² Bu açıklamalarımızdan çıkardığımız önemli bir sonuç; İtalyan ceza hukuku teorisinin etkisiyle Türk hukukunda kabul görmüş olan “önşartlar” kavramının (DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku*, cilt I, 12. bası, İstanbul, Ocak 1997, no. 451 vd.) gereksiz olduğudur (Aynı doğrultuda görüş için bkz. KUNTER, Suçun Maddi Unsurları, sh. 73/74; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 89 vd.; ALACAKAPTAN, Suçun Unsurları, sh. 6; CENTEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 150; ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 6. bası, sh. 106; DEMİRBAŞ, Genel Hükümler, sh. 178).

²⁶³ “Hırsızlık fiiline iştirak etmeksizin, cürümden hasıl olan (eşyayı) bilerek kabul eden (şahsın) fiili, TCK’nın 512. maddesindeki suç oluşturur: 6. CD., 31.3.1993, 1354/3051 (Erdurak, Yılmaz Güngör: *Notlu İçtihatlı Türk Ceza Kanunu*, 3. bası, Ankara, Ocak 1994, sh. 996). Yeni TCK’nın 165’inci maddesinde tanımlanan suç eşyasını satın alma suçunun oluşabilmesi için, satın alınan ve suçun konusunu oluşturan eşyanın, bir suçun işlenmesiyle elde edildiği hususunda kastın olması gerekir.

²⁶⁴ Meselâ, çalınan eşyanın bir başkasına ait olması.

²⁶⁵ İfade etmek gerekir ki; ceza hukuku açısından önem arzeden netice, kanunî tarifte yer alan neticedir. Kanunî tarifte yer almayan neticeler, hukuken veya en azından ceza hukuku açısından önemi haiz değildir. Bu itibarla, netice, işlenen fiilin bir unsuru değil, belli bir suçun kanunî tarifindeki bir unsuru oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, “*fiil=hareket+netice*” şeklindeki formül, isabetli değildir. Kanunî tarifte yer alan netice, fiilin yanı sıra, fiilin sebebiyet verdiği, suçun yine kanunî tarifinde yer alan bir maddi unsuru olarak anlaşılmalıdır. Bu şekildeki anlayış, özellikle teşebbüs ve içtima bahsine ilişkin meselelerin çözümünde farklı bir izah metodolojisinin izlenmesini gerekli kılmaktadır.

²⁶⁶ Kastla ilgili bilmenin kapsamı hakkında bkz. PUPPE, Ingeborg: *Vorsatz und Zurechnung*, Heidelberg, 1992, sh. 35 vd.

²⁶⁷ Yargıtay 15. Ceza Dairesinin **1.10.2018** tarihli ve E. 2015/11789, K. 2018/6143 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, A, bir gün önce bilgisayar satın aldığı B’nin hırsızlık suçundan dolayı yakalandığını öğrenmesine rağmen, ilgili mercilere durumla ilgili olarak bilgi vermez. Bu olayda, İlk Derece Mahkemesi A hakkında TCK, m. 166’da tanımlanan “**Bilgi vermeme**” suçundan dolayı mahkumiyet hükmü kurmuştur.

mesken olduğunu bilmekle beraber başkasına ait olduğunu bilmeyen ya da sahibinin rızasının olmadığını bilmeyen kimsede konut dokunulmazlığını ihlâl kastı bulunmamaktadır.

Kişi, gerek fail olarak kendisine ilişkin gerek mağdurun objektif vasfına ilişkin olarak suçun kanunî tarifinde belirtilen hususların bilincinde olmalıdır. Meselâ, fail veya mağdurun *kamu görevlisi* olması, mağdurun üst soydan veya alt soydan biri olması ya da belli akrabadan olması, mağdurun “*onbeş yaşını tamamlamamış*” (m. 103) veya “*onbeş yaşını bitirmiş*” bir çocuk olması (m. 104), suçun “*beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı*” işlenmesi (m. 82, f. 1, bent (e); m. 86, f. 2, bent (b); m. 95, f. 2, bent (a))²⁶⁸.

Suçun kanuni tanımındaki unsurlar, *tanımlanabilir* (tasvirî, deskriptif) veya *değerlendirilebilir* (normatif)²⁶⁹ nitelikte unsurlar olabilirler. Ancak belirtmek ge-

Ancak, Yargıtay 15. Ceza Dairesi, “*değerinin altındaki fiyata bilgisayar satın alan ve aynı mahiyetteki ürünlerin alım satımı üzerine esnaflık yapan A’nın, bu eşyanın suç eşyası olduğunu bilmesi gerektiği* anlaşılmakla, eyleminin TCK’nın 165. maddesi kapsamında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışıl” madan, 166. maddede tanımlanan suçun oluştuğunun kabulüyle kurulan bu mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay’ın bu kararında bilmekle bilmesi gerekme yani kast ile taksir birbirine karıştırılmıştır.

²⁶⁸ Ancak, belirtelim ki; Yargıtay, bir kararında bu esasa aykırı bir görüş benimsemiştir:

«Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 15.1.1962, 5/4 ve 15.10.1962, 5-54/53 gün ve sayılı içtihatlarında açıklandığı üzere; *suç faillerinin kaçırarak kadınlara evli olduklarını önceden bilmemiş olmalarının suçun evli kadına karşı işlenmiş olması durumu ortadan kaldırmayacağına* ve TCK’nın 429. maddesinin 2. fıkrasında “*evli kadının kaçırılması*” hali için ağırlaşan cezayı öngören yasa koyucu(nun), suç failinin bu suçtan ceza görebilmesini, TCK’nın 440-441/2. maddelerinde olduğu gibi, kaçırarak kadının evliliğini bilmesi koşuluna bağlamadığı (na göre;) 429. maddenin 2. fıkrası yerine 1. fıkrası ile uygulama yapılması yasaya aykırıdır.»: 5. CD., 20.4.1983, 563/1344 (YKD, Temmuz 1983, sh. 1089).

²⁶⁹ Kavramlar hakkında bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Suç İştirakin Hukuki Esası ve Faillik*, İstanbul, 1996, sh. 137; YÜCE, Turhan Tüfan: *Ceza Hukuku Dersleri, cilt I, Giriş: Genel Bilgiler. Ceza Hukukunun Yürürlüğü. Suç Teorisi*, 1982, sh. 188, 189; ÖLMEZ, Gökhan: *Suçun Tanımlanabilir ve Değerlendirilebilir Unsurları*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, 2020, sh. 62 vd. Değerlendirilebilir (normatif) unsurlar hakkındaki bilgi de kasta dahildir. Ancak, bu unsurlar hakkındaki bilgi, genel bir bilgidir (YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 323/324). Şöyle ki, meselâ evrakta sahtekârlık suçu açısından, kişinin tahrif ettiği veya sahte olarak tanzim ettiği belgenin bir fatura olduğunu bilmesi yeterlidir. Kastın varlığından bahsedebilmek için; failin bu belgenin resmî evrak mı yoksa özel evrak mı olduğu hususunda bilgi sahibi olmasına gerek yoktur.

Kunter’in suçun maddi ve manevî unsurlarının yanı sıra, ayrıca bir “üçüncü unsur” olarak normatif unsurunun mevcut olduğu düşüncesine dayanarak, bu kavrama yönelttiği eleştiriyi (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 61) isabetli bulmamaktayız. Ayrıca, ilâve etmek gerekir ki; *Kunter*’in iddiasının aksine; suçun tanımlanabilir - değerlendirilebilir unsurlarına ilişkin izah, “kusurluluk unsurunun şumulünü tayin”le doğrudan bağlantılı değildir.

Yargıtay’ın şu kararı suçun normatif unsurları açısından bir örnek teşkil etmektedir: “Torunun gayrimişru birleşme sonucu dünyaya getirdiği ... iki aylık çocuğu, S’nin *muhafaza yükümlülüğü*(nün) bulunmamasına ... (göre), tuvaletteki masanın üzerine bırakıp ... gi(tmesinden

reker ki, maddi unsur bağlamında suç tanımında yer alan bütün kavramların az veya çok hem tanımlanabilir hem de değerlendirilebilir yönü mevcuttur.

Hırsızlık suçunda (TCK, m. 141 vd.) suçun konusunu oluşturan malın bir başkasına ait olduğunu, yani failin kendi mülkiyetinde olmadığını bilmesi gerekmektedir. Hırsızlık suçuna ilişkin kastın varlığı için, kişi çaldığı mal ile kendisi dışında belirli veya belirsiz bir başkası arasında mülkiyet ilişkisinin olduğunu bilmesi gerekmektedir.

Kendini idare etmekten *aciz* olan ve ancak başkalarının yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayabilen bir kişiye karşı kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde, failin bu nedenle daha ağır ceza ile cezalandırılabilmesi için (TCK, m. 82, f. 1, bent e) aranan kast bakımından, öldürdüğü kişinin “*beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan*” birisi olduğunu bilmesi gerekir.

Cinsel istismar suçunun (TCK, m. 103) manevi unsurunu oluşturan kast bağlamında, failin, cinsel arzularını tatmin için istismar ettiği kişinin çocuk olduğunu, duruma göre henüz onbeş veya onsekiz yaşını tamamlamamış bir kişi olduğunu bilmesi gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki, bu bilme doğum tarihlerinin yıl, ay ve gün itibarıyla bilinmesini gerekli kılmamaktadır. Failin fiili işlediği sırada mağdurun onbeş veya onsekiz yaşını doldurmamış bir kişi olduğu algısıyla hareket etmiş olması, bu suça ilişkin kastın varlığı için yeterlidir.

Görevinin icrasından dolayı kamu görevlisine hakaret etmesi dolayısıyla (TCK, m. 125, f. 3, bent a) hakkında cezaya hükmedilebilmesi için, failin, kişiye kamu adına üstlendiği görevin gereklerini yerine getirmesinden dolayı hakaret etmesi, yani hakaret ettiği kişinin görevli olduğunu bilmesi yeterlidir. Başka bir ifadeyle, hakaret suçunun bu nitelikli unsurundan dolayı faile ceza verilebilmesi için, bu kişinin TCK’nın 6. maddesindeki tanım kapsamına giren kamu görevlisi olduğunu bilmesine gerek bulunmamaktadır.

Belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için, failin üzerinde tahrifat yaptığı şeyin, bir hukuki durumu tespit eden fonksiyon gördüğünü bilmesi yeterlidir. Örneğin otomobilin plakasında yetkisiz olarak değişiklik yapan kişi, değişiklik yaptığı şeyin, salt bir teneke parçasından ibaret olmadığını, bir hukuki durumu tespit eden bir fonksiyon gördüğünü bilmesi, resmi belgede sahtecilik suçunun (TCK, m. 204) manevi unsurunu oluşturan kastın varlığı bakımından yeterlidir. Ancak, belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için, plakanın bir “resmi belge” olduğunun fail tarafından bilinmesine gerek yoktur. Keza, kişinin üzerinde tahrifat yaptığı yazılı kağıdın bir hukuki durumu tespit eden fonksiyon icra ettiğini bilmesi, kastın varlığı için yeterli olup; bu belgenin resmi veya özel belge olduğunun fail tarafından bilinmesine gerek bulunmamaktadır.

ibaret fiilinde) suçun kast unsuru bulunma”maktadır: CGK., 13.4.1987, 8-21/208 (Savaş/Mollamahmutoğlu IV, birinci bası, sh. 4734; İçel/Yenisay, dördüncü bası, sh. 810).

Fail, suç teşkil eden fiilin icra ediliş şekline ilişkin olarak kanunî tanımda belirtilen hususların da bilincinde olmalıdır. Örneğin, icbar suretiyle irtikâp suçunun oluşabilmesi için, kamu görevlisi, “*görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatle bulunulmasına bir kimseyi icbar*” etmelidir (m. 250, f. 1). Fail, bu suçu işlerken bütün bu hususların bilincinde olmalıdır.

Bu hususlar, suçun temel şekline ilişkin unsurlar olabileceği gibi; suçun nitelikli unsurları dahi olabilir. Örneğin hırsızlık suçunda çalınan şeyin, “*bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya*” olduğunun failce bilinmesi gerekir (m. 141, f. 1, bent [d]).

İşlediği fiille ilgili olarak bir hukuka uygunluk sebebi mevcut ise, fail bu hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarının gerçekleştiğinin bilincinde olmalıdır. Yani, bu şartlar konusundaki bilgi, kast kapsamında mütalâa edilen bilgidir^{270, 271}.

Bu itibarla, işlediği fiil açısından bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları esasen gerçekleşmediği halde, bu şartların gerçekleştiği zannıyla hareket eden kişinin işlediği suç açısından kastının varlığından bahsedilemez²⁷².

Belirtilen mülahazalarla, yeni TCK’da kastın tanımı yapılırken, “*suçun kanunî tanımındaki unsurlar*” ibaresi kullanılmış iken (m. 21, f. 1); hata konusunda düzenlemenin yer aldığı 30. maddenin birinci fıkrasında ise, “*suçun kanunî tanımındaki maddi unsurlar*” ibaresi kullanılmıştır.

İşlenen fiilin haksızlık muhtevası belirleyen unsurların bilinmesiyle, bu fiilin bizatihî haksızlık teşkil ettiğinin bilinmesi, mahiyet itibarıyla birbirinden farklılık arz etmektedir²⁷³. Kişi, gerçekleştirdiği fiilin bütün unsurlarını bilmekle beraber, bu fiilin bir haksızlık ve dolayısıyla, suç teşkil ettiğini bilmeyebilir^{274, 275}.

²⁷⁰ Biz, daha önce, doktora tezimizde aksi görüşe taraftar olmuştuk: Bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 214 vd. Ancak, isabetsiz olduğunu düşünerek bu fikrimizi değiştirmiş bulunmaktayız.

²⁷¹ Katoğlu, bu bağlamdaki görüşümüzü eleştirirken aslında doğru bir tespitte bulunmaktadır. (KATOĞLU, Hukuka Aykırılık, sh. 114, dn. 611).

²⁷² Türk Hukuk doktrininde her ne kadar objektif teoriye iltifat edilmekte ise de; Dönmezer/Erman, bu tür bir yanılgi halinde meseleyi unsur yanılıgına (“fiilî hataya”) müteallik mantık çerçevesinde halletmektedirler (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 699.). Yine, adı geçen yazarlar, bu yanılginın kaçınılabilir olması halinde dahi, kanunun mevcut düzenlemesi karşısında faile ceza verilemeyeceği fikrindedirler. Ancak, belirtelim ki, yeni TCK’na ilişkin Hükümet Tasarısında aksi yönde hüküm konmuştur:

“Kendisine kusur olarak isnadı mümkün olmayan bir hata dolayısıyla hukuka uygunluk nedenlerine ait koşullara uyduğunu sanan kimseye ceza verilmez” (Tasarı, m. 23, “bent” 3.).

²⁷³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, 214 vd.; aynı yazar, *Uygulamalı Ceza Hukuku*, 2. bası, İstanbul, 1998, sh. 35, 187 vd.

²⁷⁴ Meselâ 1475 sayılı İş Kanunu, m. 85, f. 1’de “(i)şçilere iş ve işlere işçi bulmak için, kazanç amacıyla olsun veya olmasın, faaliyet gösterilmesi, çalışılması veya büro açılması yasak”lanmıştır. Aynı Kanunun 105. maddesinin 1. fıkrasına göre, “... bu fiilleri yapanlar hakkında, eylem başka bir suçu oluştursa dahi, ayrıca ... hapis ve ... ağır para cezası hükmolur”

Buna rağmen kişi bu fiil açısından kasten hareket etmiştir. Ancak, işlediği fiilin bir haksızlık ifade ettiğinin bilincinde olmadığı için, kişiyi bu fiili gerçekleştirmesi nedeniyle kusurlu telâkki etmemekteyiz.

Suçun kanunî tarifinde yer almakla birlikte, fiilin haksızlık muhtevasında etkili olmayan hususlar kast kapsamına dahil edilmezler. Meselâ **objektif cezalandırılabilme şartının** arandığı suçlarda bu şartın gerçekleştiğinin bilinip bilinmemesi, kastın varlığı açısından önem taşımamaktadır. Çünkü, söz konusu şartın gerçekleşip gerçekleşmemesinin işlenen fiilin haksızlık muhtevası üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Örneğin hileli iflas veya taksirli iflas suçlarından dolayı cezalandırılabilirlik için “*iflâsa karar verilmiş olması*” gerekmektedir (m. 161, 162). Nitekim, bu suçlara ilişkin madde gerekçesinde, “*iflâs olgusunun gerçekleşmesi(nin), bir objektif cezalandırılabilme şartı*” oluşturduğu açıkça vurgulanmaktadır. Keza, Kanunun “*Mal veya hizmet satımından kaçınma*” başlıklı 240. maddesinde “*belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak fiili suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suçtan dolayı failin cezalandırılabilmesi için, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak suretiyle kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekir. Böylece, kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması, söz konusu suçun bir objektif cezalandırılabilme şartını oluşturmaktadır.*”

Bunun gibi, suçun oluşması için *şahsi cezasızlık sebebi* veya *cezaı kaldıran şahsi sebeplerin* fail tarafından bilinmesi gerekmez.

Şahsi cezasızlık sebepleri, failin iter criminise girdiği andan itibaren mevcut olan sebeplerdir. Meselâ, izlenen suç siyaseti mülahazasıyla, aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerinin malvarlığına karşı işlemiş bulundukları hırsızlık suçundan dolayı cezalandırılmaları cihetine gidilmemektedir (m. 167, f. 1). Ancak, Kanun koyucu, bazı durumlarda failin işlediği suçtan dolayı büsbütün cezalandırılmamasını değil de, cezasında indirim yapılmasını uygun görmektedir (m. 167, f. 2). Bu gibi durumlarda *cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep* söz konusudur.

nur”. Dikkat edilmelidir ki; “bu fiillerin içten ve iyiniyetle yapılmış olması halinde dahi, suç oluşacaktır” (SELÇUK Sami: CGK.’nın 30.3.1987 tarih ve 6-441/154 sayılı Kararına muhalefet şerhi: Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1061 vd. [1070]). Bir başka ifadeyle; kişi bu fiilleri işlerken insanî mülahazalarla, başkalarının iş bulmasına yardımcı olmak amacıyla hareket etse dahi, Kanunda tarif edilen “suç” gerçekleşmiş olacaktır!

²⁷⁵ Ancak, Yargıtay, işlenen fiilin bizzatî haksızlık teşkil ettiği hususundaki bilgiyi kasta dahil etmektedir. Bir başka ifadeyle; şayet fail işlediği fiilin haksızlık teşkil ettiğini bilmiyor ise, işlediği fiil açısından kasdının varlığından bahsedilemeyecektir:

“Seçim bittikten sonra muhafazası lazım gelen oy pusulalarını sanığın yakmasının, lüzum kalmadığı yolundaki kanaatinden ileri geldiğini müdafaaten beyan eylemesine göre; bu müdafaa hilâfında kasdı cürmî takip ettiği hakkındaki sübut delilleri gösterilmeksizin mahkûmiyet kararı verilmesi” hukuka aykırıdır: 3. CD., 18.1.1951, 10370/234 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, birinci bası, sh. 577); aynı doğrultuda CGK., 10.10.1952, 941/942 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, birinci bası, sh. 547. Bu konuda bilgi için ayrıca bk. KUNTER, Kanunî Unsurlar, sh. 71).

Buna karşılık **cezayı kaldıran şahsi sebepler** ise, suç tamamlandıktan sonra gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle, suç teşkil eden fiil işlenirken, kişinin cezalandırılmasını engelleyen herhangi bir durum mevcut değildir. Ancak, suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkan bazı şartların varlığı durumunda, kişiye hiç ceza verilmemekte ya da cezasında indirim yapılmaktadır. *Cezayı kaldıran* ya da *cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler* (m. 93, 110, 168, 184 [f. 5], 192, 201, 221, 248, 254, 269, 274, 293).

Fail, suç tamamlandıktan sonra, etkin pişmanlık gösterebilir. İşlenmiş ve tamamlanmış olan suç, bu pişmanlık dolayısıyla işlenmemiş hale irca edilememektedir. Ancak, işlenen haksızlığın neticeleri fail tarafından mümkün olduğunca izale edilmektedir²⁷⁶.

Gerek şahsi cezasızlık sebebinin gerek cezayı kaldıran şahsi sebeplerin ortak özelliği, bu sebeplerin varlığı durumunda işlenen fiilin suç niteliğinde ve haksızlık muhtevasında herhangi bir değişiklik ve azalma meydana gelmemesidir²⁷⁷.

Kanunun söz konusu 21. maddesi gerekçesinde bu durum açık bir şekilde ifade edilmektedir:

“Suç tanımında yer almakla birlikte, fiilin ifade ettiği haksızlık üzerinde etkili olmayan koşulların gerçekleştiğinin bilinip bilinmemesi, kastın varlığı açısından önem taşımamaktadır. Örneğin objektif cezalandırılabilme koşulunun arandığı suçlarda bu koşulun veya şahsi cezasızlık sebebinin fail tarafından bilinmesi gerekmez.”

Buraya kadar yapılan açıklamalara göre; kast, suçun maddi unsurlarının fail tarafından bilinmesini ifade etmektedir. Buna karşılık, yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısında kast, “*eylem ve neticesi*”ne yönelik bilgiye inhisar ettirilmiştir. Keza, Hükümet Tasarısında, klasik suç teorisinin etkisiyle, kastın bilme unsurunun yanı sıra isteme unsuruna da yer verilmiştir (Tasarı, m. 20). Buna göre, kast, bilme ve isteme olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Ayrıca, belirtmek gerekir ki, Hükümet Tasarısında yer verilen kast tanımı Türkçe dilbilgisi kuralları açısından da yanlıştır:

“Kast, eylemi ve neticesini bilerek ve isteyerek işlemek iradesidir.” (m. 20, f. 1, ikinci cümle)²⁷⁸.

Bu yanlışlıkta, Yargıtay’ın kararlarında kullandığı ifade biçimi²⁷⁹ ve doktrindeki bazı görüşler²⁸⁰ etkili olmuştur^{281, 282}.

²⁷⁶ Bu hususta bkz. Ask. Yarg.5. D., 18.2.1987, 99/88 (Ask. Yarg. KD, 6(1990), sh. 73).

²⁷⁷ Bununla bağlantılı diğer bir özellik ise, iştirak halinde işlenen suçlarda, bu sebeplerin varlığı halinde bunun diğer suç ortaklarına sirayet etmemesidir.

²⁷⁸ Ayrıca bkz. TCK 1989 Öntasarısı, m. 21, f. 2; 1997 Öntasarısı, m. 21, f. 1.

²⁷⁹ Bkz. CGK., 9.4.1990, 1-60/108 (YKD. Temmuz 1990, sh. 1066 vd.).

Yeni TCK’da da kastın bilme ve isteme unsuruna yer verilmiştir:

“*Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.*” (m. 21, f. 1, ikinci cümle).

Bu düzenlemede etkili olan klasik görüşe göre, kastın iki unsuru bulunmaktadır. Bunlar, bilme ve isteme unsurlarıdır²⁸³.

Bu ayırımın gereği olarak kast, aynı zamanda suçun unsurlarının somut olayda gerçekleşmesi yönündeki iradeyi gerektirmektedir. Ancak, bu irade, kusurluluk bağlamında aranan “*kişinin davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneği*”nin varlığını gerektirmez. Kast kapsamında aranan irade, insan davranışının *mutlak kuvvetin* (*vis absoluta*) etkisinde gerçekleşmemesini gerektirmektedir.

Kanımızca, istemek, kastın bir unsurunu oluşturmamaktadır. Yani, kişi işlediği fiilin sonuçlarını öngörmüş ise, bunların gerçekleşmesini istemese bile, kasten hareket etmiştir. Örneğin, kişi *meçbur* edildiği bir fiili işlemesi durumunda, bunun sebebiyet vereceği sonuçların bilincindedir. Her ne kadar bu fiili işlemeyi ve sebebiyet verdiği neticenin gerçekleşmesini istememiş ise de, bu durumda failin kasten hareket ettiği hususunda tereddüdümüz yoktur²⁸⁴. Bu itibarla, kast

²⁸⁰ Bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 446; ALACAKAPTAN, Uğur: *Suçun Unsurları*, Ankara, 1970, sh. 139; YÜCE, Turhan Tufan: *Ceza Hukukunun Temel Kavramları*, Ankara, 1985, sh. 59; HAFIZOĞULLARI, Zeki: *Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezaî Himayesi*, in: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 48, yıl 1999, sayı 1-4, sh. 1 vd. (5).

²⁸¹ ÖZGENÇ, İzzet: *Bilinçli Taksir*, in: Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı (Galatasaray Üniversitesi yayını), İstanbul, 2004, sh. 697 vd.

²⁸² Ancak belirtmek gerekir ki, bu tutarsız açıklamaların izlerine Yargıtay’ın günümüzde verdiği kararlarda da rastlamaktayız:

“**Sonuçlarını bilerek ve isteyerek fiili işleme iradesi** olan ve failin iç dünyasını ilgilendiren kast, failin olay öncesi, olay sırası ve **olay sonrası davranışları** ölçü alınarak belirlenmelidir.” (CGK, **2.3.2010**, E. 2009/1-252, K. 2010/46; CGK, **8.7.2008**, E. 2008/1-88, K. 2008/184). Bu kararların diğer tutarsız bir yönü de, kastın belirlenmesi bağlamında failin “*olay sonrası davranışları*”nın da dikkate alınmasından söz edilmesidir. Kastın belirlenmesinde failin fiili işledikten sonraki davranışlarının da dikkate alınmasını öngören bu ilginç kabulün bilimsel bir temeli bulunmamaktadır (Aynı yönde diğer kararlar için bkz. CGK, **20.1.2009**, E. 2008/1-232, K. 2009/2; CGK, **18.9.2012**, E. 2012/1-941, K. 2012/1780).

²⁸³ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 2. bası, sh. 230 vd.; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 917; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 443 vd.; SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 414 vd.; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, İkinci Bölüm, §1, III, 2, C; ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 6. bası, sh. 186; CENTEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 306; DEMİRBAŞ, Genel Hükümler, sh. 313.

²⁸⁴ Ancak, Yargıtay’ın aksi yönde kararları mevcuttur:

«Mazgirt Jandarma Birlik Komutanlığında Hareket-Eğitim Astsubayı olan sanık T’nin, 19.10.1994 tarihinde bir teröristin cesedi üzerinden Tim Komutanı Astsubay M tarafından düzenlenen tutanak ile elde edilen suç konusu tabancayı mal edinmek amacıyla gerçek tutanağı ortadan kaldırıp, yerine tabancadan söz etmeyen sahte tutanağı düzenleyen Jandarma Birlik Komutanı diğer sanık Yüzbaşı A’nın sahte tutanağı imzalaması konusundaki önerisini önceleri reddederek olumsuz tutum sergilemesine rağmen; onun “*bu tutanak mutlaka imzalanacak; imzala-*

açısından isteme unsurundan söz edilmesinin doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bu ayırım, kastın bir kusurluluk şekli olarak kabulünün bir sonucudur.

Failin, işlediği suçun maddi unsurları hakkındaki bilgisine göre; kast, *doğrudan kast* ve *olası (muhtemel, gayrimuayyen) kast* olmak üzere, ikiye ayrılmaktadır.

1) Doğrudan Kast

Fail, işlediği suçun maddi unsurlarının bütününi düşünmüş, öngörmüş ve dolayısıyla, bütün bunlar hakkında bilgiye sahip olmuş ise, *doğrudan kast* söz konusudur. Bir suçun işlenmesi kararlaştırılmış, bu suçun maddi unsurları ve özellikle işlenen fiilin günlük hayat tecrübelerimize göre *muhtemel surette* sebebiyet vereceği neticeleri öngörülmüş ise; fail doğrudan kastla hareket etmiştir²⁸⁵. Örneğin, A'yı öldürmek için silahını bu şahsı hedef alarak ateşleyen B, A'ya karşı öldürme suçunu doğrudan kastla işlemiştir.

Keza, örneğin bir siyasi şahsiyeti öldürmek amacıyla bu kişinin bindiği uçağa bomba yerleştiren failler, bu bombanın patlaması sonucunda uçakta bulunan diğer kişilerin de günlük hayat tecrübelerimize göre *muhtemel surette* öleceğini öngörmüşlerdir. Bu itibarla, gerçekleştirilen fiilin *muhtemel surette* sebebiyet vereceği neticeler açısından da doğrudan kastla hareket edilmiştir.

Belli bir neticenin gerçekleştirilmesi amacıyla yönelik olarak işlenen fiilin diğer bazı neticeleri de meydana getireceği *muhtemel* ise; fail bu neticeler açısından da doğrudan kastla hareket etmiştir²⁸⁶. Pencere camının arkasında bulunan kişiyi yaralamak için atılan taş ile pencere camının *muhtemel surette* kırılacağı öngörülmüştür.

İşaret etmek gerekir ki; icra edilen fiilin günlük hayat tecrübelerimize göre *muhtemel surette* sebebiyet vereceği neticeler, öngörülmüş olmasına rağmen her nasılsa gerçekleşmemiş olabilir. Örneğin, sigorta şirketinden tazminat alabilmek

mazsanız ben yapacağımı bilirim” diyerek, ayrıca sicilini bozacağından ve uzak karakola süreceğinden söz ederek tehdit etmesi üzerine, *askeri disiplin, bölgenin olağanüstü hal özelliği ve görevin hayati tehlike arzemesi gibi zor koşullar* nazara alınıp değerlendirildiğinde; *ciddi ve endişe verici boyutlarda olduğunun kabulü gereken bu tehdit ve baskının etkisi altında* kalarak imzalamak *mecburiyetinde* kaldığı; oluşa göre de bir “maledinme” ilişkisi içerisinde de olmadığı; tehdit ve baskının ortadan kalkmasını müteakip, yaklaşık dört ay sonra olayı adli mercilere ihbar ettiğinin anlaşılması karşısında; *suçunun manevi kast ögesi itibarıyla oluşmadığı* gözetilmeden, yazılı şekilde zimmete iştirakten mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.»: 5. CD., 1.7.1998, 1757/2832 (Yaşar, İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, sh. 450).

“SİT alanında bulunan tapulu evine su sızması nedeniyle *zaruret* karşısında inşaat yapmak zorunda kalan sanıkta suç işlemek kastının bulunduğu söylenemez.” CGK, 13.3.1995, 9-41/64 (Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 536/537). Ayrıca bkz. CGK, 20.9.1993, 9-167/247 (Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 558/559).

²⁸⁵ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 930; ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 6. bası, sh. 191.

²⁸⁶ ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, İkinci Bölüm, §1, III, 2, E, b; CEN-TEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 312.

için geminin açık denizde batırılması fiilinin gemide bulunan kişilerin boğularak ölmesine sebebiyet vereceği günlük hayat tecrübelerimize göre muhakkaktır. Ancak dalgalarla boğuşan kişilerin o bölgeden geçmekte olan başka bir yük gemisinde bulunanlar tarafından fark edilmesi üzerine kurtarılmaları mümkündür. Kanaatimizce bu durumda gemiyi batırma fiilini gerçekleştiren şahısların ayrıca kasten öldürme suçuna teşebbüsten dolayı sorumlulukları cihetine gidilmelidir²⁸⁷.

2) Olası (Muhtemel) Kast

Yeni TCK'nın 21. maddesinin ikinci fıkrasında, olası kasta ilişkin hükme yer verilmiştir. Buna göre,

“Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde, olası kast vardır.”

Olası (muhtemel, gayrimuayyen) kast (*dolus eventualis*)²⁸⁸ halinde, bir suçun kanunî tanımındaki maddi unsurların gerçekleşebileceği, fail tarafından *öngörülmektedir*. Bu öngörme olgusu itibarıyla, olası kast, (bilinçsiz) taksirden ayrılmaktadır. Buna karşılık, doğrudan kasttan farklı olarak, olası kast halinde; somut olayda suçun maddi unsurlarının gerçekleşmesi, fail tarafından muhakkak değil, *muhtemel* addedilmektedir.

Belli bir neticenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak işlenen fiilin diğer bazı neticelerin oluşumuna *muhtemelen* sebebiyet vereceği öngörülmüş ise; bu neticeler açısından olası kastla hareket edilmiş demektir. Fail, gerçekleştirdiği fiilin muhtemel bazı neticeleri meydana getirebileceğini düşünmüş, bu neticelerin gerçekleşmesini mümkün ve muhtemel olarak tasavvur etmiş ise; bu neticeler açısından olası kastla hareket etmiştir. Fail fiili işlerken bu neticelerin muhtemelen gerçekleşebileceğini öngörmüş ve bunları kabul etmiştir²⁸⁹.

²⁸⁷ Aksi düşünce, DÖNMEZER/ERMAN II, no. 930. *Dönmezer/Erman*'a göre amaçlananın dışında zorunlu olarak gerçekleşen neticeler dolayısıyla fail ancak gerçekleştikleri takdirde ve ölçüde sorumlu olur. Dolayısıyla amaçlananın dışında kalan bu neticelerin gerçekleşmemesi halinde fail bu neticeler itibarıyla teşebbüs hükümlerine göre sorumlu tutulmayacaktır.

²⁸⁸ Öztürk/Erdem'in olası kastla ilgili olarak kullandıkları “koşullu kast” ibaresi (ÖZTÜRK/ERDEM, *Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku*, 9. bası, sh. 198 vd.) doğru değildir.

²⁸⁹ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, *Suç Teorisi*, 2. bası, sh. 234/235; ÖZGENÇ/ŞAHİN, *Uygulamalı Ceza Hukuku*, sh. 153/154; ÖNDER, *Genel Hükümler II*, sh. 295, 303, 304; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 931; ARTUK/GÖKCEN/AL-ŞAHİN/ÇAKIR, *Genel Hükümler (13)*, sh. 435; CENTEL, *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, sh. 312; ÖZTÜRK/ERDEM/ÖZBEK, *Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku*, 6. bası, sh. 191; DEMİRBAŞ, *Genel Hükümler*, sh. 322/323. “Dolaylı kast” kavramı olarak bkz. SOYASLAN, *Genel Hükümler*, 3. bası, sh. 415 vd.; BOZBAYINDIR, Ali Emrah: *Türk ve Mukayeseli Ceza Hukukunda Olası Kast Kavramı ve Sınırları*, Ankara, Ekim 2018, sh. 54 vd.; KARA-KEHYA, Hakan: *Olası Kast*, in: *Ceza Hukuku Dergisi*, yıl 1, sayı 2, Aralık 2006, sh. 28 vd.

İşlenmesi kararlaştırılan fiilin, kanunen tarif edilen muayyen bir neticenin gerçekleşmesine sebebiyet vereceği muhtemel telâkki edilmiş olmasına rağmen; bu neticenin gerçekleşmesi *kabullenilmiştir*. Olası kast halinde, kanunî tarife uygun neticenin gerçekleşmesi, *olayın seyrine bırakılmaktadır*. Kişi, neticenin gerçekleşmesini muhtemel addetmekle birlikte, bunun *gerçekleşmemesi için özel bir çaba göstermemektedir*²⁹⁰. Kanunî tarife uygun neticenin meydana geleceği muhtemel addedilmesine rağmen, fail fiili işlemekten geri kalmamıştır^{291,292,293}.

Bir görüşe göre, bilme bir kesinlik ifade etmektedir; bu nedenle “doğrudan kastın söz konusu olduğu her halde, netice bakımından bir kesinliğin bulunması gerekli değildir”; keza, “ihtimal dahilinde olan, (yani) öngörülen neticenin istenmesi halinde de doğrudan kast söz konusu olabilmektedir.” (KARAKEHYA, Hakan: *Ceza Hukukunda Doğrudan Kast*, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 15, yıl 2007, sayı, 1, sh. 121 vd.; aynı yazar: *İradilik Unsuru Bağlamında Ceza Hukukunda Kast*, Ankara, 2010, sh. 54 vd.). Buna karşılık, yazara göre, “doğrudan kast, sadece zorunlu sonucun bilinmesinden ibarettir”. Zorunlu “sonuç irade edilmese bile, istenmiş gibi kabul edilir.” Yazar, doğrudan kastı “birinci dereceden doğrudan kast” ve “ikinci dereceden doğrudan kast” olarak ikiye ayırmaktadır. “İradenin (istemenin) varlığı halinde birinci dereceden doğrudan kast söz konusu olacaktır. Failin zorunlu sonucu biliyor olması, ikinci dereceden doğrudan kastın varlığının kabulü için yeterlidir.” (KARAKEHYA, Selçuk ÜHFD, cilt 15, yıl 2007, sayı, 1, sh. 124; aynı yazar, *Ceza Hukukunda Kast*, sh. 43 vd.). “Kastın isteme unsurunun gerçekleştiği hallerde, zihinsel açıdan failin neticeyi öngörmesinin veya bilmesinin herhangi bir önemi yoktur. Her ikisinde de fail birinci dereceden doğrudan kasttan sorumlu olacaktır. ... İstemenin söz konusu olmadığı hallerde”, neticenin gerçekleşme ihtimali “muhakkak veya muhakkaka yakınsa ... fail neticeyi istemese bile istemiş gibi kabul olunur” ve “ikinci dereceden doğrudan kast” söz konusudur (KARAKEHYA, Selçuk ÜHFD, cilt 15, yıl 2007, sayı, 1, sh. 127; aynı yazar, *Ceza Hukukunda Kast*, sh. 87 vd.).

Bu görüş, iradeyi kastın bir unsuru olarak kabul eden klasik suç teorisinin bir yansımasıdır. Söz konusu görüş doğrudan kastla olası kast arasındaki ayırımı iradeye bağlamaktadır. Yani muhtemel neticenin gerçekleşmesi yönünde iradenin varlığı halinde artık doğrudan kast söz konusu olmaktadır. Ayrıca, söz konusu anlayış, amacı kastın yoğunlaşmış hali olarak kabul etmektedir. Halbuki, aşağıda da açıklanacağı üzere, amaç, bazı suç tanımlarında kastın dışında ayrı bir manevi unsur oluşturmaktadır. Yazarın açıklamalarının diğer bir dikkat çeken yönü ise, bilme veya öngörme ile istemeyi çoğunlukla, suçun maddi unsurlarından sadece netice ile ilişkilendirmesidir.

²⁹⁰ Olası kastın kabulü için, neticenin gerçekleşebileceği yönündeki ihtimal, tek başına bir ölçüt olarak kabul edilemez; kabullenme unsurunun da varlığı gereklidir. Bu itibarla failin, öldürmek istediği kişiye hedef ittihaaz ederek silahla ateş ettiği sırada iyi nişan alamaması sebebiyle isabet ettiremeyebileceğini düşünmesi, bu öldürme suçu bakımından doğrudan kastının olmadığı anlamına gelmez. Fail, iyi nişan alamadığı için hedefe isabet ettiremeyebileceği ihtimalinin bilincinde olmasına rağmen, hedef ittihaaz ettiği kişiye silahla ateş etse ve fakat hedefe isabet ettiremese, doğrudan kastla hareket etmiştir ve fakat hedefe isabet ettiremediği için, kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır.

²⁹¹ Aynı doğrultuda açıklama için bkz. ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, İkinci Bölüm, §1, III, 2, E, b; MAHMUTOĞLU, İstanbul ÜHFM, LXIII(2005), sayı 1-2, sh. 88; KARAKEHYA, CHD, Aralık 2006, sh. 28 vd.

²⁹² CGK, 9.4.2013, E. 2013/1-78, K. 2013/136:

“5237 sayılı TCK’nın 21. maddesinin 1. fıkrasında; suçun kanuni tanımındaki unsurların bile-
rek ve istenerek gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmış olan kast, öğretide de genel kabul gö-
ren düşünceye göre; suçun kanuni tanımında yer alan objektif unsurların bilinmesi ve isten-

Olası kast sadece netice açısından değil, suçun diğer maddi unsurları bakımından da söz konusu olabilir.

Olası kastla ilgili olarak uygulamamızdan şu örnekler verilebilir:

Kişi, eline geçirdiği eski bir tabancayı bir kaç defa tecrübe eder ve tabancanın ateş almadığını gözlemler; “nasıl olsa patlamıyor” düşüncesiyle ağzında mermi bulunan bu silahı “şaka” yapmak için arkadaşına yönelterek tetiğine basar; bu kez ateşlenen tabancadan çıkan tek kurşun maktule isabetle ölümüne sebebiyet verir. Bir insanın ölümüne sebebiyet verilen bu olayda, failin olası kastla hareket ettiğini kabul etmek gerekir²⁹⁴.

mesi biçiminde tarif edilmiştir. Görüldüğü gibi kast, bilme ve isteme şeklinde ifade edilen iki unsurdan oluşmaktadır. Fail, hareketinin kanuni tipi gerçekleştireceğini biliyor ve bunu istiyorsa kasten hareket ettiği kabul edilmelidir, ancak failin hareketiyle hedeflediği doğrudan sonuçların yanı sıra, hareketinin zorunlu sonuçları ya da kaçınılmaz yan sonuçları da, açık bir isteme olamasa dahi kast kapsamında değerlendirilmelidir.

Olası kast ise aynı kanunun 21. maddesinin 2. fıkrasında; “öngörmesine rağmen fiili işlemesi” şeklinde tanımlanmış, bu kast türü ile ilgili başkaca ayırıcı bir unsura yer verilmemiş, 5237 sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasında bilinçli taksirin; “*Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır*” şeklinde tanımlanması nedeniyle, bu kast türünün bilinçli taksirle karıştırılacağı hususu öğretide dile getirilmiş, kanun koyucu da, madde metninde yer vermediği “kabullenme” ölçüsüne, madde gerekçesinde; “*olası kast durumunda suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda gerçekleşeceği öngörülmesine rağmen, kişi fiili işlemektedir. Diğer bir deyişle, fail unsurların meydana gelmesini kabullenmektedir*” şeklinde açıklamak suretiyle, olası kastı bilinçli taksirden ayıracak ölçüyü ortaya koymuştur.

Olası kast ile doğrudan kast arasındaki ayırıcı ölçüye gelince, buradaki en belirgin unsur, doğrudan kasttaki bilme unsurudur. Fail hareketinin kanuni tipi gerçekleştireceğini biliyorsa doğrudan kastla hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir. Yine failin hareketiyle hedeflediği doğrudan neticelerle birlikte, hareketin zorunlu veya kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sonuçları da, açıkça istenmese dahi doğrudan kastın kapsamı içinde değerlendirilmelidir. Belli bir sonucun gerçekleşmesine yönelik hareketin, günlük hayat tecrübelerine göre diğer bazı sonuçları da doğurması muhakkak ise, failin bu sonuçlar açısından da doğrudan hareket ettiği kabul edilmelidir.

Olası kastı doğrudan kasttan ayıran ölçüt, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşmesinin muhakkak olmayıp, muhtemel olmasıdır.” Ayrıca bkz. CGK, 10.12.2013, E. 2012/9-1456, K. 2013/608; CGK, 31.3.2015, E. 2014/1-619, K. 2015/80; CGK, 10.5.2016, E. 2014/1-200, K. 2016/250.

²⁹³ TCK’nın olası kasta ilişkin düzenlemesinin Anayasaya aykırılığı yönünde ileri sürülen itiraz, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. (19.2.2009, E. 2005/107, K. 2009/23: RG: 30 Mayıs 2009/27243).

²⁹⁴ Ancak, Yargıtay, benzer bir olayda taksirin varlığını kabul etmiştir:

«Henüz çocuk yaşta bulunan sanık her nasılsa ele geçirdiği tabancayı olaydan önce birkaç kez tecrübe etmiş ve her defasında tabancanın patlamadığını bizzat görüp tespit etmiş ve bu tecrübesine dayanarak olay günü de “nasıl olsa patlamıyor” düşüncesiyle ve şaka yapmak arzu ve gayesiyle maktule tevcih edip tetiğe basmış, bu kez ateşlenen tabancadan çıkan tek kurşun maktule isabetle ölümüne sebebiyet vermiştir.

Bu nedenle, (sanığın fiilini “dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu adam öldürmek” olarak tavsif eden) Özel Daire bozma kararı yerindedir: CGK, 12.12.1983, 1-112/391 (Önder, Ayyhan/Özek, Çetin: *Ceza Hukuku Pratik Çalışma Gereçleri*, 2. bası, İstanbul, 1987, sh. 318 vd.).

Keza, şehirlerarası yolda seyreden bir otobüs sürücüsü, trafik lambasının kendisine kırmızı yanmasına rağmen, kavşaktan durmadan geçmek ister. Ancak trafik lambası yeşil yanan diğer yönden gelen bir otomobilin *trafikte güven prensibine* uygun olarak kavşaktan geçtiği sırada otobüs otomobile çarpar ve bir veya birkaç kişinin ölümüne sebebiyet verir. Trafik lambası kendisine kırmızı yanan sürücü trafik lambasının yeşil yandığı diğer yönden bir aracın gelmekte olduğunu görür. Fakat, buna rağmen kavşaktan geçmeye karar verir. Bu durumda otobüs sürücüsünün, meydana gelen ölüm neticesi açısından *olası kastla* hareket ettiğini kabul etmek gerekir²⁹⁵.

Kalabalık içinde bulunan bir siyasi şahsiyet hedef alınarak ateşlenen silahtan çıkan mermi hedeflenen şahsa değil, hemen yanındaki kişi veya kişilere isabet eder. Bu durumda, meydana gelen netice açısından failin *olası kastla* hareket ettiğini kabul etmek gerekir²⁹⁶. Ancak, fail hedef aldığı kişi açısından arzu ettiği neticeyi riske sokmamak için, silahını “tarama” şeklinde müteaddit defa ateşlemiş olabilir. Bu durumda gerek hedef alınan kişiye gerek isabet alan diğer kişilere yönelik olarak *doğrudan kastla* öldürme suçu işlenmiş olur²⁹⁷. Çünkü, bu durumda, hedef

Bu kararda çoğunluk görüşüne karşı olan üyeler; sanığın fiilinin *kasten adam öldürmek* suçunu oluşturduğu gerekçesiyle ve sanığa TCK'nın 448. maddesiyle tayin edilmesi gereken cezanın 2253 sayılı Kanunun 12/2. maddesi uyarınca tespit edilmesi gerektiği fikrindedirler.

Kanaatimizce bu olayda *olası kastla öldürme* suçu işlenmiştir (Bkz. ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku, 2. bası, sh. 110). Nitekim Yargıtay'ın söz konusu kararına muhalefet eden üyeler aynı doğrultuda görüş beyan etmişlerdir.

²⁹⁵ «Trafik olay tespit tutanağında sanığın kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yola devamı sonucu kendisine yeşil ışık yandığı için yola giren ölenin aracına çarptığının belirtilmesine; çarpılan otoda bulunan tanık B.nin bu oluşu doğrulaması yanında, diğer tanıklarca da olay yerinde olduğu söylenen minibüs sürücüsü tanık A.nın anlatımının da bu yolda olmasına göre; trafik tespit tutanağını düzenleyenler tanık olarak dinlenilip oluşun nasıl saptandığı sorulduktan sonra, başkaca tespit verileri gösterildiğinde bunların da toplanması ve tüm deliller otobüste bulunan ve aksi beyanı tutanaklara geçirilmiş olan tanıkların anlatımları ile birlikte irdelenmesi, oluşun takdir ve kabulünün hakime ait olduğu gözetilerek; mevcut deliller muvacehesinde oluşun ne yolda kabul edildiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi ve kabul edilen duruma göre kusur oranı sorulup, sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken; noksan inceleme ile ve oluş mahkemece belirlenmeden, raporda gösterilen ve bilirkişiye ait olmayan değerlendirmeye istinaden (tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten) hüküm kurulması» doğru değildir. 2. CD., 25.9.1997, 11794/12180 (YKD. Mart 1998, sh. 441).

²⁹⁶ ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku, 2. bası, sh. 102.

²⁹⁷ «Sanık öldürücü nitelikte bir silâh olan tabancasını insanların bulunduğu salon ve odaya doğru ufki vaziyette tutarak iki el ateş etmiş olmasına göre, orada bulunanlardan birinin vurulup ölebileceği bilinci içindedir. Sanık kalabalığa ateş ederek bir kişiyi öldürmüş olmasına göre *adam öldürmek kastıyla hareket etmiş* ve fakat özel olarak ölmüş olanı öldürmek istememiştir. Burada adam öldürmek istemiş olması, kastın varlığı ve suçun sübutu için yeterlidir.

TCK'nın 448. maddesinde yalnızca kasıttan bahsedilmiştir. 448. maddede muayyen bir şahsın öldürülmesi şeklinde bir koşul mevcut değildir. *Belirli olmayan kasılla* da suç oluşabilir. Örneğin; bir panik yaratmak için kalabalığın üstüne bomba atmak gibi. Sanık gerek belirli ve gerekse belirsiz şekilde ve fakat sonucu istemiş ise onda adam öldürmek kastı da var demektir. Fail kalabalığa ateş ederek bir kişiyi öldürmüştür, burada *failin maksadı adam öldürmektir.*»:

alınan kişi dışında ölümüne neden olunan diğer kişilerin de isabet alacağı, günlük hayat tecrübelerimize göre muhtemel değil, muhakkak surette öngörülür.

Bir kişinin otomobiline bomba yerleştirilmesi halinde, bu kişiye karşı doğrudan kastla öldürme suçu işlenmiş olur. Ancak otomobilde öldürülen kişiden başka birinin olabileceği veya bombanın infilak edeceği anda ve yerde başka kişi veya kişilerin de ölebileceği muhtemeldir. Bu gibi durumlarda hedeflenen kişi harcinde ölen veya yaralanan kişiler açısından *olası kastla* hareket edilmiş olur.

Yargıtay, son kararlarında bu ölçütleri dikkate alarak, suçun olası kastla işlendiği yönünde içtihatla bulunmuştur^{298,299}.

CGK., 5.3.1979, 1-483/95 (Keskin, O. Kadri: *Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Sebebiyet*, Ankara, 1991, sh. 173/174); aynı mealde CGK., 19.4.1982, 1-11/147 (Keskin, sh. 170 vd.).

«Olay gecesi 01.30 sularında N'nin oğlunun evlenmesi sebebiyle düğün evinde sanık ve arkadaşlarının bir odada toplu olarak içki içip eğelendikleri sırada, yer sofrasının etrafında oturanlardan M'nin silahıyla tavana birkaç el ateş etmesinden sonra, yanındaki sanık S de tabancasını çıkarıp pencere istikametine doğru en az üç el ateş etmiş ve oradaki seki üzerinde oturan A, başından aldığı isabetle, ölmüştür.

Olayın geçtiği düğün evindeki oda fazla geniş değildir; içeride onbeş onaltı kişilik bir topluluk bulunmaktadır. Maktul ile beraber beş altı kişi de odanın içinde ve pencerenin önünde yerden kırk santimetre kadar yükseklikteki seki üzerinde oturmaktadır. Sanık oturduğu yerden pencere istikametine doğru en az üç el ateş etmiş ve orada seki üzerinde oturanlardan A, başından aldığı isabetle, ölmüştür. Maktulün, sanık S'nin tabancası ile yapılan atış sonucu aldığı isabetle öldüğü, sabittir. Belirtilen şekilde yapılan atış sonucu objektif olarak ölüm neticesinin meydana gelebileceği doğal görüldüğünden; sanığın sorumluluğu, *gayrimuayyen kasta* dayanan bir sorumluluktur. Buna göre eylem, TCK'nın 448. maddesine uyan suçu oluşturur.» CGK, 6.2.1996, 1-339/10 (Yaşar, Osman: *İçtihatlı Türk Ceza Kanunu*, Ankara, 2001, sh. 988/989).

«Sanığın, traktörde birkaç kişinin bulunduğunu görerek, iki el ateş etmesinde eyleminin sonucuna katlanarak dört yaşındaki maktulün öldürülmesinden ötürü *gayrimuayyen kastla* hareket ettiğinin kabulü ile, ayrıca TCK'nın 448. maddesi ile ceza verilmesi gerekirken, TCK'nın 79. maddesinin uygulanması» hukuka aykırıdır: 1. CD., 23.11.1996, 3293/3700 (Yaşar, İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, sh. 1000).

«Gece vakti pencereleri kapalı cama içeridekileri görmeden hedef alarak seçmeden müteaddit sayıda silahla ateş etmesinin müessir fiile teşebbüs niteliğinde olduğu (kabul edilerek) şüpheden sanık yararlanır kuralı gereği (olarak failin,) TCK'nın 456/4, 662, 457/1, 51/1, 55/3, 59. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekir.» 1. CD., 17.5.1999, 806/1820 (Yaşar, İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, sh. 994).

²⁹⁸ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun **7.6.2011** tarihli ve E. 2011/1-54, K. 2011/120 sayılı kararında yapılan tespit ve değerlendirmeyi sonuç itibarıyla doğru bulmaktayız:

“... (T)*artıştığı diğer sanığı korkutarak olay yerinden kaçırmak gayesiyle hareket eden ve kimseyi özellikle hedef almayan sanığın, doğrudan öldürme veya yaralama kastı ile hareket etmediği, ancak elindeki elverişli silahla ve silahın etki alanı içerisinde kendisinin de oturduğu ve maktulün öldüğü apartman da dâhil olmak üzere çok sayıda yüksek katlı ev bulunan şehir merkezinde havaya doğru iki el ateş etmesi sonucunda, mermilerden birinin herhangi birisine isabet edebileceğini öngördüğü, buna rağmen ateş etmek suretiyle öngördüğü neticeyi göze aldığı ve kabullendiği, bunun sonucunda da maktulün ölümüne neden olduğu olayda, eyleminin, “olası kastla öldürme” suçunu oluşturacağı kabul edilmelidir.”*

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kast, doğrudan kast ve olası kastla ilgili genel açıklamaların yer aldığı kararları için bkz. CGK, **3.7.2012**, E. 2012/1-407, K. 2012/262; CGK, **22.5.2012**, E. 2011/1-480, K. 2012/207.

²⁹⁹ **Olay I.** A, otomobiliyle gidiş dönüşlü (iki şeritli) devlet karayolunda seyretmekte iken, özel ses ve ışık sistemi aktif olarak arkadan gelmekte olan ambulans aracını fark etmesine rağmen, üç kilometre boyunca bu aracın sollayarak geçişini engeller. Ambulans aracı sürücüsü, asfalt yol dışına çıkarak, A'nın otomobilini geçmeyi başarır.

Hastaneye yetiştirilmeye çalışılan hamile kadın (H), bu nedenle ve özellikle asfalt yolun dışına çıkılmasının meydana getirdiği sarsıntının etkisiyle ambulans aracında erken doğum yapar. Ancak, bebek (B) hastaneye varıncaya kadar hayatını kaybeder.

Hukuki değerlendirme: Ambulans aracın özel ses ve ışık sistemi aktif olarak arkadan gelmekte olması, **acil tıbbi müdahaleyi gerekli kılan hasta** birinin bu araçta bulunduğu ya da çağrı üzerine aracın bu kişiyi almaya gitmekte olduğuna işaret eder. Ambulans aracın, üç kilometre boyunca geçişinin engellenmesi, acilen gerçekleşmesi gereken tıbbi müdahalenin gecikmesi sonucunu doğurur. Tıbbi müdahalenin gecikmesinin hastanın sağlığının kötüleşmesine ve hatta hayatını kaybetmesine sebebiyet verebileceği **öngörülür**.

Yol iki şeritlidir. Bu itibarla, öndeki araç sürücüsü A'nın, ambulans aracın geçebilmesi için yol kenarına çekilmesine gerek bulunmamaktadır. Aksine, karşı yönden gelenlere tahsis edilmiş olan sol şeridin müsait olduğu durumlarda, ambulans aracın sollayarak geçmesini de engellemiştir. Bu nedenle, olayda **icrai davranışla** işlenmiş bir fiil mevcuttur.

Bu durum karşısında, A'nın **olası kastla** hareket ettiğini kabul etmek gerekir. Ambulans araç sürücüsü içinde bulunduğu **zorunluluk hali** koşulları sebebiyle, asfalt yolun dışına çıkmış ve araçta meydana gelen sarsıntı hamile kadının doğum yapmasına sebebiyet vermiştir. Uygun olmayan ortamda dünyaya gelen B, hastaneye kavuşturuluncaya kadar hayatını kaybetmiştir. Bebek, dünyaya geldikten sonra ölmüştür. Bu durum karşısında, A'yı **olası kastla öldürme suçundan** sorumlu tutmak gerekir.

Asfalt zemin dışına çıkmaya mecbur kalacak şekilde ambulans aracın geçişinin engellenmesi, aynı zamanda **trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması suçunu** oluşturur.

Bu durumda **farklı neviden fikri içtima** hükümlerinin uygulanması gerekir.

Bu engellemeye rağmen, hasta hastaneye kavuşturulmuş ve kendisine gerekli tıbbi müdahalelerde bulunulmuş olması durumunda, bu engellemeye bağlı olarak herhangi bir netice meydana gelmemiştir. Bu durum karşısında, A'nın ceza hukuku sorumluluğu, **olası kastla işlenmiş olan suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanabilirliği sorunu** ile bağlantılı olarak çözülme kavuşturulması gerekmektedir.

Olay II. H ve arkadaşı M, sevk ve idarelerindeki otomobillerle, şehrin ana caddelerinden birinde gece saatlerinde yarış ederler; yaklaştıkları kavşakta kendilerine kırmızı ışık yanmasına rağmen, durmadan ve hatta hızlarını azaltmadan kavşaktan geçmeye çalışırlar. H, bu sırada kendisine yeşil ışık yanan ve kavşaktan geçmekte olan E'nin otomobiline çarpar. Kazada, E hayatını kaybeder.

H ve M hakkında açılan kamu davasında, H savunma olarak, kazanın gecenin geç saatlerinde, saat 0.40'da meydana geldiğini, bu saatlerde trafiğin yoğun olmadığını, alkollü olmadığını, kendisinin oto tamircisi olduğunu, kullandığı otomobilin gerekli güvenlik donanımlarına sahip bulunduğunu, sürüş sırasında otomobilin kontrolünü kaybetmediğini, kaza sırasında kendisine kırmızı ışık yandığını ve kavşağa bir otomobil girdiğini fark etmediğini, ileri sürer.

Hukuki değerlendirmemiz:

Söz konusu olayda, H ve M, sevk ve idarelerindeki otomobillerle şehrin ana caddelerinden birinde **yarış** ederler. Bu kişiler,

- gece geç saatlerde de olsa, araçla şehir içi trafiğinde belirli bir hızın üzerinde seyredilemeyeceğinin,
- cadde üzerinde kavşakların ve yaya geçitlerinin bulunduğunun,
- trafikte seyrederken, her an önlerine bir araç veya kişi çıkabileceğinin,

bilincindedirler.

Bu itibarla, her iki kişi de birbirleriyle yarış halinde iken önlerine bir araç veya kişi çıkabileceğini öngörmektedirler.

Yarış psikolojisiyle hareket eden kişinin, trafik düzenine ilişkin kurallar bakımından dikkatsiz ve özensiz hareketinden ziyade, **trafik kurallarını hiçe sayan hareketinden** söz edebiliriz. Zira yarışçı, rakibine veya rakiplerine üstün gelebilmek için, kendi yeteneklerini ve kontrolündeki aracın kapasitesini azami ölçüde kullanan kişidir. Yarış psikolojisiyle hareket eden kişi bakımından güzergahta yaya geçitlerinin ve kavşakların, trafik güvenliği bakımından konulmuş azami hız sınırlarının ve bu bağlamda trafik işaretlerinin bulunmasının bir önemi yoktur. Hatta, yarış psikolojisiyle hareket eden kişinin trafik işaretlerinin yeterince farkına varabilmesinden de söz edilemez. Bu psikolojiyle araç kullanan kişi bakımından bir araca veya başkasına çarpmamak için bir gayret ve çaba içinde olmaktan söz edilemez. Bu itibarla, söz konusu durumlarda, bilinçli taksirin değil, **olası kastın** varlığını kabul etmek gerekir.

Belirtilen nedenlerle, olayda olası kastla işlenmiş öldürme suçu söz konusudur. Bu suç sadece E'nin aracına çarpan H'nin değil, H ve M'nin müşterek fail sıfatıyla işledikleri bir suçtur. H ve M, trafik düzenine ilişkin kuralları hiçe sayacak şekilde araç kullanmaya müştereken karar vermişlerdir. Bu müşterek karar çerçevesinde hareket eden kişilerden herhangi birinin bir başkasına çarpması ve ölümüne sebebiyet vermesi halinde, diğerinin fiili ile bu ölüm neticesi arasında doğal bir fenomen olarak illiyet bağının bulunduğu hususunda kuşku yoktur. Bu itibarla, söz konusu olayda H ve M'yi E'ye karşı **olası kastla** işlenmiş kasten öldürme suçundan dolayı **müşterek failler** olarak (uygulama sırası itibarıyla, TCK, m. 81; m. 21, f. 2; m. 37, f. 1 hükümlerine istinaden) sorumlu tutmak gerekir.

Berlin'de cereyan etmiş olan bu olayın bir benzeri, Türkiye'de gerçekleşmiştir. **Yargıtay Ceza Genel Kurulunun** yakın tarihli bir kararına konu teşkil eden olayda, A ve B, iki şeritli Devlet karayolunda sevk ve idarelerindeki otomobilleriyle seyir halinde iken birbirleriyle yarış ederler. Bu yarış sırasında, sağ şeritte seyreden B'nin önüne bir kamyon çıkar. Ancak, A'nın aracıyla aynı hızda veya çok az bir mesafe farkıyla seyrettikleri için, B hemen sol şeride kayarak kamyonu geçemez ve otomobilinin sağ tarafından kamyonu çarpar. Bu çarpma sırasında B'nin otomobilinin sağ ön koltuğunda oturan C hayatını kaybeder.

Bu olayda Türk yargısı, B'yi *taksirle ölüme sebebiyet verme* suçundan (TCK, m. 85) sorumlu tutmaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararında tartışma konusu yapılan, C'nin ölümünden dolayı A'nın ceza hukuku sorumluluğu yoluna gidilip gidilemeyeceği hususudur. Oy çokluğuyla bir sonuca bağlanan söz konusu karar, gerekçesini gördüğümüzde ayrıca ve özellikle bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Buna karşılık, Yargıtay aşağıdaki olaylarda ceza hukuku sorumluluğunun olası kast çerçevesinde değil de **bilinçli taksir** çerçevesinde değerlendirilmesi yönünde içtihatla bulunmuştur:

Olay III. Yargıtay 12. Ceza Dairesinin **12.6.2018** tarihli ve E. 2016/7497, K. 2018/6677 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, yolcu taşımacılığı yapan şoförler A ve H, “önceden yolcu kapmaya dayalı rekabet sebebiyle” sevk ve idarelerindeki midibüsleri birbirleriyle yarışarak sür'atli sürerler. Bu yarış sırasında H, A'nın aracını solladıktan sonra, asgari mesafe ölçütüne riayet etmeden tekrar sağ şeride geçer. H'nin aniden önüne çıkması dolayısıyla A, bu araca çarpmamak için, sağ tarafta yolun dışına çıkar. Ancak, A aracın kontrolünü kaybeder. Aracın tarlaya savrulması sonucunda, yolculardan on iki kişi çeşitli yerlerinden yaralanırlar.

İlk derece mahkemesi bu olayda, H hakkında çok sayıda kişinin bilinçli taksirle yaralanmasına sebebiyet vermekten dolayı mahkûmiyet hükmü kurar, A'nın ise, beraatına hükmeder.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda, H'nin “idaresindeki araç ile yarışır vaziyette seyreden A'nın da olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği” gerekçesiyle, hakkında verilen beraat hükmünü bozulmasına karar verir.

Olay IV. Yargıtay 12. Ceza Dairesinin **2.3.2017** tarihli ve E. 2017/248, K. 2017/1603 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, T ile R, sevk ve idarelerindeki otomobillerle gidiş geliş iki şeritli ve ortasından çift sarı çizgi ile bölünmüş olan caddede, birbirleriyle yarış ederler; T,

B. Doğrudan Kast ve Olası (Muhtemel) Kast Ayırımının Yasama Faaliyeti ve Uygulama Açısından Önemi

Kasten işlenebilen bir suç, hem doğrudan kastla hem de olası kastla işlenebilir. Ancak, bir suçun kanunî tanımında “*bilerek*”, “*bildiği halde*”, “*bilmesine rağmen*” gibi ifadelerle yer verilmiş ise, bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir. Başka bir deyişle, kanunî tarifinde “*bilerek*”, “*bildiği halde*”, “*bilmesine rağmen*” gibi ifadelerle açıkça yer verilen suçlar, olası kastla işlenemez^{300, 301}.

Bu suçlar açısından TCK'daki en önemli örnek, iftira suçudur (m. 267).

İftira suçunun faili, iftira konusu haksız fiilin, kendisine isnatta bulunulan şahıs tarafından işlenmediğini bilecektir. Bu itibarla, iftira suçu ancak *doğrudan kastla* işlenebilir. Bu suç, olası kastla işlenemez.

Fail, gerçekten işlenen bir suçla alâkalı olarak ihbar/şikayet hakkını kullanırken, bu suçun belli bir şahıs veya şahıslar tarafından işlendiğinden şüphelenmiş olduğunu da beyan edebilir. Bu durumda iftira suçu oluşmaz³⁰². Çünkü, bu durumda gerçekten işlenmiş olan suçun muayyen bir kişi tarafından işlenmiş olduğu hususunda kesin yargıda bulunulmamaktadır³⁰³.

R'yi geçmeye çalışır. Bu sırada T'nin otomobilinin sağ yanı R'nin otomobilinin sol yanına temas eder. Araçlar birbirine bitişik vaziyette bir süre seyrettikten sonra, R araç hakimiyetini kaybeder. R'nin kontrolden çıkan aracı, yolun sağındaki otobüs durağında bekleyen çok sayıda yolcuya çarparak, ölümlerine sebebiyet verir.

İlk derece mahkemesi bu olayda, T hakkında, bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne sebebiyet vermekten; R hakkında ise, (bilinçsiz) taksirle çok sayıda kişinin ölümüne sebebiyet vermekten dolayı mahkûmiyet hükmü kurar.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda, her iki kişinin “meskûn mahal şartlarının çok üzerinde bir hızla”, birbirleriyle “yarışır vaziyette” seyretmeleri sebebiyle, R'nin de bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne sebebiyet vermekten dolayı mahkûm edilmesi gerektiği gerekçesiyle, ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar verir.

³⁰⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Ekonomik Çıkar amacıyla İşlenen Suçlar*, Ankara, 2002, sh. 285; aynı yazar: *Suç Teşekkülü, Düşünceyi Açıklama ve Örgütlenme Hürriyeti*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Türkan Rado'ya Armağan Sayısı, cilt LV, yıl 1997, sayı 3, sh. 51 vd. (54); ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 459, 488, 529. Ayrıca bkz. ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner: *Uygulamalı Ceza Hukuku*, 2. bası, Ankara 2003, sh. 762 vd.

³⁰¹ Bu husus madde gerekçesinde de vurgulanmıştır:

“Kasten işlenebilen suçlar, ilke olarak hem doğrudan hem de olası kastla işlenebilir. Ancak, kanundaki tanımında “*bilerek*” ifadesine yer verilmiş olan suçlar sadece doğrudan kastla işlenebilir. Örneğin iftira suçunda, failin suçsuz olduğunu “*bilerek*” kişiye suç isnad etmesi gerektiğinden, bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir.”

³⁰² BAYRAKTAR, Köksal: *İftira*, İstanbul ÜHFM, yıl 1974, cilt XL, sayı. 1-4, sh. 201; ÖNDER, Ayhan: *Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler*, 3. bası, İstanbul, Eylül- 1991, sh. 45.

³⁰³ «Oluşa ve dosya içeriğine göre, geceleyin evinden bazı eşyalarının alınmış olduğunu ve o gün devamlı olarak kendisini ve evini sorduğu için alacaklısı Mehmet'den şüphelendiğini bildiren

Alman hukukunda bu husus, “*wider besseres Wissen*” (“bilmesine rağmen”) kavramıyla ifade edilmiştir. Nitekim, Alman Ceza Kanununda bu kavramın yer aldığı suçlarla ilgili açıklamalarda; söz konusu suçların ancak doğrudan kastla işlenebileceği ve buna karşılık olası kastla işlenemeyeceği belirtilmektedir³⁰⁴.

765 s. Kanunda suç eşyasını satın alma suçu, ancak *doğrudan kastla* işlenebilen bir suç olarak tanımlanmıştı (765 s. TCK, m. 512). Çünkü, Kanundaki suç tanımında “*bilerek*” ifadesi kullanılmıştı. Ancak, belirtelim ki, Kanunda doğrudan kastın aranmasına rağmen; uygulamada muhtemel kastın varlığı halinde de suçun oluştuğu kabul edilmekte ve failin cezalandırılması yoluna gidilmekteydi.

sanığın, bu savunmasının aksini kanıtlayan kesin ve inandırıcı hiçbir delil elde edilmediği anlaşıldığından; yasal şikâyet hakkını kullanmış sayılacağı, bu nedenle müsnet suçun unsurlarının teşekkül etmediği gözetilmeden mahkûmiyetine karar verilmesi, ... bozmayı gerektirmiştir.»: 4. CD., 22.1.1985, 8571/120. (YKD, Nisan 1985, sh. 587 vd.).

“Sanıklar, kanunî takip yapma yetkisini haiz bulunan C. Savcısına, ... Bankası Müdürünün kendilerinden kredi karşılığı 100.000 lira rüşvet aldığını ifade ederek, suçsuzluğuna bildikleri halde ona suç isnat etmişlerdir. Bu nedenle) fiilleri, iftira suçunu oluşturur.”: 4. CD. 21.10.1986, 6677/7562 (YKD, Mayıs 1987, sh. 781).

Ancak Yargıtay’ın şu kararından varılan sonuca iştirak etmiyoruz:

«Dosyaya, oluşa ve delillere göre; müdahil Mehmet’in oğlu, Mevlüt’ün yeğeni, İsmail’in akrabası Mesut’un, sanık Hatice’nin oğlu, Fındık’ın kocası Hikmet tarafından öldürüldüğü iddiası ile adı geçen hakkında adam öldürmek, sanıklar Fındık ve Hatice haklarında da suç delillerini saklamak suçlarından kamu davası açılması nedeniyle, taraflar arasında şiddetli bir düşmanlık bulunduğu, olay gecesi gelin-kaynana olan sanıkların beraber oturdukları evlerinin ahırının kiledi kırılmak suretiyle, daha önceden müdahillerden satın aldıkları ancak bedelini ödeyemedikleri için müdahiller tarafından alınıp, götürülen ve bilahare bedeli ödenerek geri alınan ineğin çalınıp müdahiller Mehmet ve Mevlüt’ün oturdukları Tatar Köyü’ne götürüldüğü, bunun üzerine sanık Fındık’ın, bu fiilin faillerinin müdahiller olabileceği kesin kanı ve yargısı ile ihbar ve şikâyetle bulunduğu ve adı geçenler hakkında hırsızlık suçundan soruşturmaya başlandığı, soruşturma aşamalarında ithamını yoğunlaştırdığı; sanık Hatice’nin de çelişik ve değişik biçimde ve hırsızlık suçunun sanıkları müdahillerle mevcut düşmanlığını da açıklayarak, hazırlık ve ilk soruşturma aşamasında failleri görmediğini beyan ettiği halde, son soruşturma aşamasında müdahilleri ineği götürürlerken gördüğünü söylemek suretiyle tanıklık yaptığı, yapılan yargılama sonunda hırsızlık suçunun sanıkları olan müdahillerin hükümlülüklerine yeter, kesin ve inandırıcı bir kanıt elde edilemediğinden beraatlerine karar verildiği anlaşılmaktadır. Olayın açıklanan oluş biçiminden de anlaşılacağı gibi taraflar arasında uyumsuzluk konusu olmuş bir inek alış veriş vardır. Satıcı durumunda olan müdahil taraf bedeli ödenmedi diye ineği alıp götürmüş, alıcı taraf bedeli ödeyip ineği geri almıştır. Bu arada öldürme olayından dolayı aralarında ileri derecede düşmanlık baş göstermiştir. Sanık Fındık, suç delillerini saklamaktan, kocası Hikmet de adam öldürmekten yargılanmışlardır. Olay gecesi sanıkların ineğinin çalındığı bir gerçektir. Bu nedenlerle sanık Fındık’ın, ineğin müdahiller tarafından çalındığı kesin kanı ve yargısı ile ihbar ve şikâyetle bulunmak ve giderek ithamını yoğunlaştırmaktan ibaret olan fiilinde iftira suçunun kasıt unsurunun oluştuğu düşünülemez. Hırsızlık suçunun sanıkları olan müdahillerin beraatlerine karar verilmiş olması da sanığın iftira suçunu işlediğinin kesin delili olamaz.»: CGK., 12.5.1980, 8-139/203 (YKD, Ekim 1980, sh.1415 vd.).

³⁰⁴ İftira suçu (falsche Verdaectigung, Alman CK, § 164) için bkz. LENCKNER, Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 23. Auflage, München 1988, § 164, kn. 30; gerçek olmayan isnatla hakaret suçu (Verleumdung, Alman CK, §187) için bkz. LENCKNER, Schönke/Schröder(23), kn. 5.

Kanun metni ile uygulamamız arasındaki bu çelişkiyi giderebilmek için, yeni TCK'da söz konusu suça ilişkin tanımda “bilerek” ifadesi kullanılmamıştır (m. 165). Bu bakımdan söz konusu suç, doğrudan veya olası kastla işlenebilir. Nitekim, bu husus, ilgili madde (m. 165) gerekçesinde şu şekilde ifade edilmiştir:

«Bu suç, doğrudan kastla işlenebileceği gibi, olası kastla da işlenebilir. Bu nedenle, madde metninde “bilerek” ifadesi kullanılmamıştır.»

Yeni TCK'daki pek çok suç tanımında “bilerek”, “bildiği halde” veya “bilmesin ne rağmen” ifadesine yer verilmiştir (m. 154, f. 2; m. 197, f. 2, 3; m. 199, f. 2, 3; m. 207, f. 2; m. 220, f. 7; m. 261; m. 282, f. 2; m. 297, f. 2; m. 315; m. 321). Bu itibarla, yapmış bulunduğumuz açıklamaların, söz konusu suç tanımları açısından göz önünde bulundurulması gerekmektedir.³⁰⁵

Ceza kanunlarında bir haksızlık suç olarak tanımlanırken, bunun kasten veya taksirle işlenmesine göre bir ayırım yapılmaktadır. Bunun istisnasını, bünyesinde “bilerek”, “bildiği halde”, “bilmesin ne rağmen” gibi ifadelerle yer verilen suç tanımları oluşturmaktadır. Bunun dışında, kanunda bir suç tanımı yapılırken, bu suçun doğrudan veya olası kastla işlenmesine göre bir ayırıma yer verilmez. Bu ayırım, işlediği kasıtlı suçtan dolayı fail hakkında temel cezayı belirlerken, dik-kate alınabilecek bir hususu oluşturmaktadır.

Ancak, kasten ve taksirle öldürme suçlarına ilişkin cezalar arasındaki makasın 765 s. Kanunda çok açık tutulması, Yargıtay'ı, hukuki olmayan kararlar vermeye sevketmiştir. Şöyle ki, taksirle öldürme suçundan dolayı Kanunda öngörülen “hapis” cezasının üst sınırı *beş yıldır* (765 s. TCK, m. 455, f. 1). Buna karşılık, kasten öldürme suçundan dolayı Kanunda öngörülen “ağır hapis” cezasının alt sınırı ise, *yirmidört yıldır* (765 s. TCK, m. 448). Aradaki bu *ondokuz yıllık* za-

³⁰⁵ Keza işaret etmek gerekir ki, TCK'da yer alan suçu bildirmeme suçları (m. 278, 279, 280) ancak doğrudan kastla işlenebilir.

Her ne kadar TCK'nın 278. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları metinlerinde açıkça vurgulanmış değilse de, bu fıkralara ilişkin gerekçelerde yer verilen “*bilinmesine rağmen*” veya “*haberdar olunmasına rağmen*” ibareleri, söz konusu suçun ancak doğrudan kastla işlenebileceğini ifade etmektedir.

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu da (TCK, m. 279) ancak doğrudan kastla işlenebilir. Çünkü söz konusu suçun oluşabilmesi için bir suçun işlendiğinin kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak “öğrenil”mesi gerekmektedir. Bu husus, hem söz konusu suç tanımına ilişkin madde metninde hem de gerekçesinde açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Sağlık mesleği mensubu kişilerin suçu bildirmeme suçu (TCK, m. 280) bakımından da manevi unsur olarak doğrudan kastın varlığı şarttır. Çünkü bu suç tanımına ilişkin madde gerekçesinde işlendiği **öğrenilmiş** suçtan söz edilmektedir. Bu itibarla, **işlendiği hususunda kesin bilgi sahibi olunan bir suçla** ilgili olarak ihbar yükümlülüğünün varlığından söz edilebilir. Buna karşılık, işlendiği hususunda sadece kuşkunun ortaya çıkması halinde, sağlık mesleği mensubu kişiler bakımından bildirim yükümlülüğünün varlığından söz edilemez. Hemen belirtelim ki, bu telakki, ceza hukukundaki yorum kuralları ile çelişmemektedir.

man farkı dolayısıyla, failin esasında olası kastla hareket ettiği olaylarda taksirin varlığı kabul edilmiştir.³⁰⁶

³⁰⁶ «Kasten adam öldürmek suçundan sanık R.nin TCK'nın 448 ve 59. maddeleri uyarınca yirmi sene ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin *Antalya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi*'nce 29.11.1988 gün ve 68245 sayı ile verilen hükmün ... temyizi üzerine dosyayı inceleyen *Birinci Ceza Dairesi*, 14.3.1989 gün ve 386-700 sayı ile;

"Aynı işyerinde çalışan ve aralarında hiç bir anlaşmazlık bulunmayan sanık ve ölenin aravermede gittikleri kahvehanede iken, önceden dönüp, ısınmak üzere fırına giren öleni gören sanığın, ... 'şeytanlık edip' öleni korkutmak amacıyla çalışma ve stop düğmelerine aynı anda bastığı, fakat ölenin elinden sıçrayan kanı görmesi ile öldüğünü zannederek, fırın kapağını o andaki heyecanı sebebiyle açmadan, olay yerinden uzaklaştığı ve ilk karşılaştığı tanıklara da olayı bu oluşa uygun şekilde anlattığı, ölenin havasızlıktan öldüğü ... anlaşılmaktadır.

Cürmün oluşması sanığın kastının belirlenmesi gerekir. Failin iradesinin belli bir sonuca yönelmiş olması lazımdır. Yargıtay'ın benimsediği tanıma göre '*kast, cürmün neticelerini bile-rek ve isteyerek işlemek iradesidir*'. Burada irade yalnız hareketi değil, aynı zamanda neticeyi de kapsamalıdır. Ancak bu halde cürmü kasttan sözedilebilir. Başka bir anlatımla 'istenen ile meydana gelen neticenin uygunluğu' kastı oluşturur.

Yukarıda belirlenen oluşa göre, sanığın neticeyi istediğini söylemek olanaklı değildir. Burada sanığın neticeyi istememesine rağmen, neticenin meydana gelmesi hali sözkonusudur. Başka bir anlatımla sanığı irade etmediği neticeden istisnalar dışında (TCK., m. 45/2) sorumlu tutmak mümkün değildir.

O halde sanığı tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan sorumlu tutmak gerekirken, ... kasten adam öldürmek suçundan cezalandırılması" isabetsizliğinden hükmü bozmuştur.

Yerel Mahkeme ise, 9.5.1989 gün ve 107-96 sayı ile; "olayın oluşuna göre tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermek suçundan sözedilemez. Zira sanık fırın kapısını kapattıktan sonra, aynı anda çalıştırma ve stop düğmelerine basmış, içeride çırpınırken gördüğü halde, fırın kapısını açmayarak, fırını terketmek suretiyle öleni, havasızlıktan öldürmüştür. Bu itibarla öldürme kastı vardır" gerekçesiyle önceki hükümde direnmiştir.

Bu hükmün de temyiz edilmesi nedeniyle dosya, *C. Başsavcılığı*'nın "onama" istekli 20.2.1990 gün ve 1-688 sayılı tebliğnamesiyle, Birinci Başkanlığa gönderilmekle; *Ceza Genel Kurulu*'nce okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Sanık, ısınmak amacıyla fırın içerisinde oturmakta bulunan ölene "fırın kapısını kapatayım mı?" dedikten sonra, onun olumlu cevabı üzerine fırın kapısını kapatmış, bu arada "şeytanlık" edip öleni korkutmak amacıyla aynı anda çalıştırma ve stop düğmelerine basmış, ölenin kan çıktığını görünce, girdiği psikolojik ortam (panik reaksiyon) içerisinde olay yerinden uzaklaşırken fırın kapısını açmayı düşünememiş, bu durumu ilk karşılaştıkları kişilere de anlatmıştır. Nitekim ölümün havasızlıktan oluşması da bu durumu doğrulamaktadır.

Oluşu bu şekilde belirledikten sonra, suça nitelik verebilmek için kast ve taksir kavramlarına kısaca değinmek gerekir.

"Kast", TCK'nın 45. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede "*cürümlerde kastın bulunmaması cezaı kaldırır*". hükmü yer almaktadır. Ancak kastla ilgili bir tanımlama yapılmamıştır. Açıklanan bu ifade tarzının bazı sonuçlar doğuracağı açıktır. Bunlardan birisi, cürümlerde kastın temel kusurluluk biçimi olduğunu belirtmesidir.

TCK'nın 45. maddesinde (olduğu) gibi genellikle kanunların kastı tanımla(ma)yıp, (bunu) öğreti ve uygulamaya bırakmış olması yerinde görülmektedir. Böylece sert kalıplar içinde kast kavramının sıkıştırılmamış olduğu vurgulanmaktadır. Bugün öğretide egemen olan görüşe göre "*kast, tipiklikte yer alan objektif unsurların failce bilinmesi ve istenmesi*" biçiminde tanımlanmaktadır.

Esasında suç teorisine ilişkin ilkelerden bu tarz sapmalardan kaçınmak için izlenmesi gereken yöntem, bir suça ilişkin olarak kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasındaki makasın geniş tutulması ve hakime somut olayda ceza miktarının belirlenmesinde geniş takdir yetkisi tanınmasıdır. Ancak, uygulama alışkanlıkları ve çalışma koşulları dolayısıyla Türk Hakimine güvensizliğin sonucu olarak; ülkemizdeki yasama faaliyetlerinde, suç tanımlarında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasındaki makasın dar tutulması eğilimi egemen olmaktadır. Bu eğilimin sakıncalarını ortadan kaldırabilmek için yeni TCK'ya ilişkin Hükümet Tasarısında,

“Failin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.”

şeklinde bir hükme yer verilmişti (Tasarı, m. 21, f. 2).

Bu hükümden esinlenilerek, 765 s. TCK'nın 45. maddesine 8.1.2003 t. ve 4785 s. Kanunla “bilinçli taksir”le ilgili olarak bir üçüncü fıkra eklenmişti³⁰⁷.

Yeni TCK'ya ilişkin TBMM Adalet Alt Komisyonunda yapılan çalışmalarda, bu yöntemin doğru olmadığını, doğru olanın suçun kanunî tanımında öngörülen

Bu tanıma göre kastta “istemek ve bilmek” unsurlarının bulunması gerektiği görülmektedir. Bir başka deyimle, failin neticeyi düşünmesi ve gerçekleştirmeye karar vererek hareket etmiş olması, halinde kast vardır. Kastta “bilme” unsuru “isteme”yi de gerektirmez. Zira her bilinen şey istenmiş değildir. Ancak istenmiş olan şey bilinir. O halde kasttan sözdebilmek için, failin bilmesi ve neticeyi istemiş olması gerekir.

Taksir ise failin “suç tipindeki neticeye yönelik kast içinde olmadan ve fakat zorunlu olduğu özeni gösterdiği takdirde neticenin meydana gelmesi olanaklı bulunmayan hallerde tesbit edilmiş suç tipini hukuk aykırı olarak ihlâl etmesi” halidir.

Bu tanımlamalara göre kasdı suçlarda failin, toplum düzenine karşı olan iradesi, taksirde bu düzene karşı bir uyumsuzluk ve umursamamak şeklinde görülmektedir.

Kast ve taksir kavramları üzerindeki bu açıklamalardan sonra olaya bakıldığında, sanığın savunmasına göre, sanıkta ölüm neticesine yönelik isteme iradesi bulunmamaktadır. Zira sanık savunmasında şaka yaptığını ileri sürmekte ve oluş savunmadan anlaşılmaktadır. Sanık ilk aşamada ölenin öldüğü düşüncesi ile düştüğü psikolojik ortam içerisinde fırın kapağını açmadan kahvehaneye giderken, ölenin havasızlıktan öleceğini istememiştir. Sanığın neticeyi istememesine rağmen neticenin meydana gelmesi hali sözkonusudur. Başka bir anlatımla, faili irade etmediği neticeden istisnalar dışında (TCK., m. 45/2) sorumlu tutmak mümkün değildir. Kaldı ki taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmadığı gibi, açıklanan fiili şakaya dayandığından TCK'nın 455. maddesine uyan suç (*taksirle öldürme suçu*) oluşmuştur.

Olayda cürmî kastın bulunmadığı, ağır ve yoğunlaşmış bir taksirli halin varlığı sözkonusudur.

Açıklanan nedenlerle sanığın fiili ağır taksire dayalı TCK'nın 455. maddesine uyan suçu oluşturduğundan Yerel Mahkeme direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.»: CGK, 9.4.1990, 1-60/108 [YKD. Temmuz 1990, sh. 1066 vd.]. *Erman*, bu olayda olası kastın gerçekleştiğini kabul etmektedir [ERMAN, Erman/Özek, Kişilere Karşı Suçlar, sh. 22, dn. 41].

Yargıtay'ın bu yöndeki benzer kararları için, Kitabımızın dördüncü basısının 243. sahifesinde yer alan 325 numaralı dipnotuna bakılmalıdır.

³⁰⁷ *“Failin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde ceza üçte bir oranında artırılır.”*

cezanın alt ve üst sınırı arasındaki makası açık tutmak olduğunu ifade etmemize rağmen; Komisyonda, bu hükmün Kanun metninde muhafazası yönündeki görüş kabul görmüştür. Ancak, bu görüşe karşı tarafımızdan, şayet “bilinçli taksir” konusunda Kanuna bir hüküm konulacaksa, olası kast konusunda da konması gerektiği yönünde bir itirazda bulunulmuştur. Bu itirazımız üzerine, TBMM Adalet Alt Komisyonunda Kanun metnine olası kast konusunda da hüküm konması uygun görülmüştür. Buna göre, suçun olası kastla işlenmesi halinde, doğrudan kasta göre belirlenen temel cezada (m. 61, f. 1 ve 2) indirim yapılması gerekmektedir. Bu indirimin miktar veya oranı, 21. maddenin ikinci fıkrasında gösterilmiştir³⁰⁸.

II. Taksir

A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir

Kasten işlenen suçlarda olduğu gibi, taksirle gerçekleştirilen fiillerde de haksızlık ile kusurluluk birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Taksir, artık mücerret, yalın bir kusurluluk şekli değil; haksızlığın bir gerçekleştiriliş şeklidir, kısaca bir *haksızlık şeklidir*³⁰⁹. Taksir, kasttan haksızlık muhtevası itibarıyla ayrılmaktadır.

³⁰⁸ Artuk, “karşılaştırmalı hukukta olası kast halinde ceza indiriminin kabul edildiğine rastlanmamaktadır.” diyerek, bu indirim sisteminin suç teorisi bakımından doğruluğu konusunda taşıdığı endişeyi dile getirmek istemektedir (ARTUK, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 33). Ancak, şunu belirtmek gerekir ki, bilinçli taksirin varlığı halinde taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek cezanın artırılması yönteminin benimsendiği bir sistemde, olası kastın varlığı halinde de kasten işlenen suçun cezasında indirim yapmanız gerekecektir. Bu düzenleme, Kanun metninde bilinçli taksirin düzenlenmiş olmasının zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Halbuki Kanun metninde bilinçli taksir ve olası kast kavramlarına yer verilmemiş olsaydı, hakim somut olayda taksirin bilinçli taksir veya kastın olası kast olmasını temel cezanın alt ve üst sınır arasında belirlenmesinde dikkate alacaktı. Ayrıca bkz. BOZBAYINDIR, Olası Kast Kavramı ve Sınırları, sh. 91, 322 vd.

³⁰⁹ WELZEL, Lehrbuch, sh. 130, 175; ARM. KAUFMANN, *Das fahrlässige Delikt*, in: Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1964, sh. 51; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 1124 vd.; JAKOBS, Günther: *Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt*, Berlin, 1972, sh. 34 vd.; JAKOBS, Lehrbuch, § 9, kn. 4; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 509, 523; WESSELS, Johannes: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 19. Auflage, Heidelberg, 1989, sh. 202; ROXIN, Lehrbuch, 24/1 vd., 47, 107; MAURACH/ZIPF I, sh. 211, 212; MAURACH, Reinhart/GÖSSEL, Karl Heinz/ZIPF, Heinz: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband II*, Heidelberg, 6. Auflage, 1984/ 7. Auflage, 1989, sh. 105 vd.; SAMSON, Systematischer Kommentar, Anh.zu § 16, kn. 6, 9; CRAMER, Schöнке/Schröder(23), § 15, kn. 121 vd.; SCHROEDER, LEIPZIGER KOMMENTAR zum Strafgesetzbuch, 8. Auflage, 1957; 10 Auflage, 1978 ve müteakip yıllar, § 16, kn. 122 vd.; BLEI, Hermann: *Strafrecht I, Allgemeiner Teil*, 17. Auflage, München, 1977, kn. 246; ZIELINSKI, Diethart: *Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff*, Berlin, 1973, sh. 204 vd.

Ancak Yargıtay yeni kararlarında hala taksirin bir kusurluluk şekli olduğunu kabul etmektedir.

“Taksir, ... istisnai bir **kusurluluk şeklidir**” (CGK, **8.7.2008**, E. 2008/1-99, K. 2008/185; CGK, **20.5.2008**, E. 2008/9-51, K. 2008/117; CGK, **16.10.2007**, E. 2007/9-192, K. 2007/211), “ayrıkısı bir **kusurluluk biçimi**”dir (CGK, **11.3.2008**, E. 2007/9-275, K. 2008/49. Ayrıca bkz. CGK, **6.10.2009**, E. 2009/9-189, K. 2009/220; CGK, **24.11.2009**, E. 2009/9-185, K. 2009/273).

Kasten işlenen belirli haksızlıkların suç olarak tanımlanması, kuraldır. Fakat Kanun,

“Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.”

demek suretiyle bu kuralın istisnasını getirmiştir (m. 22, f. 1)³¹⁰. Bu nedenle taksirle işlenen belli fiiller de istisnaen kanunda suç olarak tanımlanmıştır. Buna göre; taksirle işlenmiş bir fiilin cezalandırılabilir olabilmesi için, suça ilişkin kanunî tarifte bunun açıkça belirtilmesi gerekir³¹¹. Bu husus, madde gerekçesinde açık bir şekilde vurgulanmıştır³¹².

³¹⁰ Ozansü, oluşturmaya çalıştığı kendine özgü hukuki düşünce modelinde, kişinin “*bilinçsiz bir şekilde haksızlık içinde bulunması*” olarak ifade ettiği “*medeni hukuk haksızlığı*”na nazaran, “*ceza hukuku haksızlığı*”nda kişinin “*bu haksızlığın bilincine sahip*” bulunduğunu iddia etmektedir (OZANSÜ, Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 28). Bu iddianın zorunlu sonucu olarak, “*adi taksir*” yani bilinçsiz taksir, ceza sorumluluğunun nedeni olamayacaktır (sh. 28, 54). Hatta yazar daha da ileri giderek, “*adi taksirle gerçekleştirilenleri ... bir hareket olarak nitelendirem*”emektedir (OZANSÜ, Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, 54). Bu itibarla yazara göre sadece kast ve bilinçli taksir, “*objektif haksızlığın gerçekleştiriliş biçimidir*” (sh. 56). Ancak, “*kast ve bilinçli taksir arasında kural olarak kusurun yoğunluğu bakımından bir fark söz konusu olabilir.*” (OZANSÜ, Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 56). Yazar, kendi içinde henüz tutarlılığı sağlanamamış olan bu açıklamalarıyla, kast ve taksire ilişkin olarak bir teorik konsept oluşturma çabası içinde olduğunu sergilemektedir.

³¹¹ SCHROEDER, F.-C.: *Probleme der Legislatorischen Feststellung der Fahrlässigkeit (Taksirin Kanunen Tanımlanmasına İlişkin Problemler* [Tercüme: İ. Özgenç]), Türk Ceza Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler (Diskussionsbeiträge zum Entwurf des Türkischen Strafgesetzbuchs), Konya 1998, sh. 236, 257.

³¹² Buna karşılık, “*Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir.*” (5326 s. Kabahatler Kanunu, m. 9). Bu hükmün gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Suçlar kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Ancak, kanunda açıkça belirtilmiş olması halinde, taksirle işlenen fiil de istisna olarak suç oluşturabilir.

Buna karşılık, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahat türünden haksızlıklar kural olarak hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Ancak, sadece kasten veya taksirle işlenebilen fiilin kabahat oluşturabileceği konusunda kanunda hüküm bulunabilir.

Fakat, Tasarının sisteminde, kabahatler açısından da idarî ceza sorumluluğunun kabulü yani idarî para cezasına karar verilebilmesi için, fiili işleyen gerçek kişinin en azından taksire dayalı kusurunun varlığı gerekir. Başka bir deyişle, kabahatler bakımından objektif sorumluluk kabul edilmemiştir.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840).

Söz konusu Kanunun Genel Gerekçesinde bu hususla ilgili olarak şu açıklamaya yer verilmiştir:

“Suçlar kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Eğer kanunda açıkça belirtilmişse, taksirle işlenen fiil de istisna olarak suç oluşturabilir. Buna karşılık, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahat türünden haksızlıklar kural olarak hem kasten hem de taksirle işlenebilirler. Ancak, sadece kasten veya taksirle işlenebilen fiilin kabahat oluşturabileceği konusunda kanunda hüküm bulunabilir.

765 sayılı Türk Ceza Kanununun sistemine göre, failin cezalandırılabilmesi için, kabahat teşkil eden fiilin gerçekleşmiş olması yeterli sayılmıştır. Kabahat türünden bir suçun işlenmesi açısından failin kasten mi yoksa taksirle mi hareket ettiğinin araştırılmasına gerek yoktur (m. 45, f. 2). Objektif sorumluluk rejiminin benimsendiği 19'uncu yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir ürünü olan bu düzenlemenin doğru olmadığını ifade etmek gerekir. Aslında bu düzenleme, kabahat türünden bir suç işleyen kişi aleyhine olan bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki, örneğin bir başkasının malvarlığına taksirle zarar verilmiş olması durumunda kişi cezalandırılmayacaktır.

Belirtmek gerekir ki; ülkemizde taksir kavramına ilişkin doktriner açıklamalarda sadece netice göz önünde bulundurulmaktadır³¹³. Bu anlayış, taksir açısından yetersizdir. Suçun kanunî tarifinde yer alan bütün maddi unsurlar taksir kavramı kapsamında mütalâa edilebilirler. Örneğin taksirle öldürme suçunda, meydana gelen ölüm neticesi açısından taksirle hareket edilebileceği gibi, öldürülen canlının bir insan olduğu hususunda da taksirle hareket edilmiş olabilir³¹⁴.

Kasten işlenen suçlarda yönlendirici irade, hukukun önem attığı neticeye, yani kanunî tariftaki neticeye yöneliktir. Buna karşılık, taksirle işlenen haksızlıklarda ise, söz konusu irade, hukuken önem arz etmeyen bir neticeye yöneliktir. Ancak, hukuken kişiye yüklenen özen yükümlülüğüne aykırı davranıldığı için, hukukun önem attığı bir başka netice (de) gerçekleşmektedir. Bu nedendir ki, taksirle işlenen haksızlıklarda “*hareketin iradiliği*”nden söz edilmektedir³¹⁵. Ancak, işaret etmek gerekir ki; bu hareket icraî bir davranışta bulunmak şeklinde olabileceği gibi, ihmali bir davranış şeklinde de tezahür edebilir³¹⁶.

Taksirin bir özelliği, kanunî tarifte belirtilen maddi unsurlardan birinin gerçekleşmesinin *öngörülmemiş olmasıdır*³¹⁷. Fakat yalnız başına bu özellik, davranışı dolayısıyla failin muaheze edilmesi için yeterli değildir. Bunun için, ilâve olarak “*gerekli dikkat ve ihtimam*”, “*gerekli dikkat ve özen*”³¹⁸ unsuru aranmaktadır³¹⁹. Gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için kanunî tarife uygun fiilin gerçekleşeceği öngörülmemiştir. Bir başka ifadeyle, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olsaydı kanunî tarifte yer alan bir unsurun gerçekleşeceği öngörülecekti diyebiliyorsak, bu fiil taksirle işlenmiş demektir. Bu itibarla, taksirden bahsed-

Çünkü, başkasının malvarlığına zarar verme (nası ızzar) suçu ancak kasten işlenebilir (m. 516). Buna karşılık, kamu makamlarından gerekli izin alınmaksızın başkasına ait binanın duvarlarına afiş yapıştırmak, yazı yazmak gibi fiiller dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için kastının sabit olması gerekmektedir (m. 536).” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840).

³¹³ İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 23, 84, 104 vd., 107.

³¹⁴ SCHROEDER, sh. 238/239, 258/259.

³¹⁵ İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 136, 140, 154 vd.; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 972.

³¹⁶ «Başboş bırakılmış köpek, mağduru ısırması ve bu suçtan dolayı şikayette bulunulmuş olmasına göre, sanığın fiili TCK'nın 459. maddesine uyar.»: 2. CD, 7.10.1976, 7694/8473 (Keskin, sh. 178).

«Sanığın nezaretindeki çoban köpeğini başboş bırakarak başkasını ısırmasına sebebiyet verme hali, TCK'nın 459. maddesine mümas suçu oluşturur.»: 2. CD, 15.3.1983, 1764/1758 (Keskin, sh. 176).

«Tehlikeli olduğunu bildiği köpeğini bağlamayarak, muhafazasında kusur eden ve köpeğin müştekiyi ısırmasına neden olan sanığın fiili, TCK'nın 459/1. maddesine uymaktadır.»: 2. CD., 14.110.1980, 298/297 (Keskin, sh. 176).

³¹⁷ İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 104.

³¹⁸ “Obligatio ad diligentiam”.

³¹⁹ İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 105, 139 vd.; SCHROEDER, sh. 242, 263; SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 422 vd.

bilmek için, kanunî tarife uygun fiilin işlenebileceğinin **öngörülme imkânının** mevcut olması gerekir³²⁰.

Nitekim 22. maddenin ikinci fıkrasında taksir şu şekilde tanımlanmıştır:

“Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyle gerçekleştirilmesidir.”

Taksirli haksızlıklar, ontik vakıanın yanı sıra, mutlaka bir değerlendirme unsuru ihtiva etmektedir: **Objektif özen yükümlülüğüne (dikkat ve özen yükümlülüğüne) aykırılık**.³²¹

Taksirle gerçekleştirilen davranışın *haksızlık* unsurunu, *objektif özen yükümlülüğünün (dikkat ve özen yükümlülüğünün) ihlâli*, oluşturmaktadır³²². Taksirle gerçekleştirilen fiilin *haksızlık* özelliği, korunan hukuki değere ilişkin objektif özen yükümlülüğüne aykırı bir davranış olmasında tezahür etmektedir³²³. Bu nedenledir ki; burada ihlâl edilen objektif özen yükümlülüğünün mutlaka belli bir hukuki değerle alâkalı olması gerekir. Belli bir hukuki değerden mücerret, soyut bir özen yükümlülüğünün varlığından bahsedilemez³²⁴. Taksirle gerçekleştirilen davranışın haksızlık unsurunu oluşturan dikkat ve özen yükümlülüğünün tayininde, failin şahsi kabiliyetleri göz önünde bulundurulmaksızın, *objektif* esastan hareket edilir³²⁵. Dikkat ve özen yükümlülüğü, belli kişiden soyut, *gereklilik yargısı*ını ifade etmektedir³²⁶.

³²⁰ İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 108, 141.

³²¹ DEMİREL, Muhammed: *Çifte Özen Anlayışı Çerçevesinde Taksirli Suçtan Doğan Ceza Sorumluluğu*, Ankara, Mart 2022, sh. 128 vd.

³²² JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 509/510, 521 vd.; JESCHECK, Hans-Heinrich: *Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş* (Türk Ceza Hukukuna İlişkin Açıklamalar: Kayıhan İÇEL, Köksal BAYRAKTAR; Çeviri: Feridun YENİSEY), İstanbul, 1989, 1989, sh. 38; WESSELS(19), sh. 201/202, 203, 204; MAURACH/ZIPF I, sh. 211, 212; MAURACH/ GÖSSEL/ZIPF II, sh. 108 vd.; KAUFMANN Armin: Das fahrlässige Delikt (Çalışmamızdaki atıflar, bundan böyle sözkonusu makalenin aynı yazara ait “Normentheorie” kısaltma adıyla zikrettiğimiz eserin 1988 yılındaki “I. basının genişletilmiş tekrar basımı”na [erweiterter Nachdruck der 1. Auflage] ilâvesine yapılacaktır), Normentheorie, sh. 317 vd.; “trafikte gerekli özen yükümlülüğünün ihlâli” olarak WELZEL, Das neue Bild, sh. 32 vd.; aynı yazar, Lehrbuch, sh. 132 vd.; ROXIN, “objektif özen yükümlülüğü” kavramı yerine, “müsaade edilen risk” kavramını kullanmayı tercih etmektedir: Lehrbuch I, 24/11; KEÇELİOĞLU, Taksirli Suçun Dogmatığı, sh. 65 vd. Ancak, yazar, belirli bir neticenin gerçekleşmesinin bir şart olarak arandığı taksirli suçlarda (taksirle ölüme veya yaralamaya sebebiyet verme suçlarında), bu netice gerçekleşmediği takdirde herhangi bir haksızlıktan bahsedilemeyeceği fikrindedir (KEÇELİOĞLU, Taksirli Suçun Dogmatığı, sh. 115). Bu kabulün, taksirli suçun haksızlık unsuruna ilişkin açıklamalarla çeliştiğini belirtmek gerekir.

³²³ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 98.

³²⁴ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 109/110, 111.

³²⁵ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 111.

³²⁶ WELZEL, Lehrbuch, sh. 131 vd.; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 509, 510, 529. Taksirli suçun unsuru olarak, objektif özen yükümlülüğünün ihlâlini değil; failin kendi yetenekleri itibarıyla

Belli hukuki değerleri korumaya matuf davranış normları, aynı zamanda dikkat ve özen yükümlülüğünün kaynağını da oluşturmaktadır³²⁷. Dikkat ve özen yükümlülüğüne ilişkin kurallar, **pozitif hukuk metinlerine** yansımış yükümlülükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuyu ceza hukuku sorumluluğu ile sınırlı olarak ele almak gereğinden hareketle, şunu söyleyebiliriz: İnsanın hayatını ve vücut bütünlüğünü korumaya yönelik davranış normları, aynı zamanda kişiler bakımından bu hukuki değerlere yönelik dikkat ve özen yükümlülüğünü ifade etmektedirler.

Türk Ceza Kanununun taksirle ölüme veya yaralanmaya sebebiyet verme suçlarına ilişkin tanımları (m. 85, 89), kişinin hayatına ve vücut bütünlüğüne yönelik dikkat ve özen yükümlülüğünün **pozitif hukuktaki dayanağını** oluşturmaktadır. Türk Ceza Kanunundaki başka bazı suç tanımları da, mefhum-u muhalifi itibarıyla, kişilerin hayatı ve vücut bütünlüğü bakımından dikkat ve özen yükümlülüğü ifade etmektedirler.

Örneğin TCK'nın 176. maddesindeki suç tanımı, inşaat veya yıkım faaliyeti icra eden kişinin bu faaliyetle bağlantılı olarak “insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri” almakla yükümlü olduğuna işaret etmektedir.

TCK'nın 177. maddesindeki suç tanımı, hayvan besleyen kişilerin besledikleri hayvanla ilgili olarak gözetim yükümlülüğü altında olduğuna işaret etmektedir.

TCK'nın 178. maddesinde yer alan suç tanımı, herkesin gelip geçtiği yerlerde iş yapan veya bu yerlere eşya bırakan kişiler bakımından, bu faaliyetten veya bıraktığı eşyadan dolayı başkalarının zarar görmemesi için “işaret veya engeller” koyma şeklinde gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü ifade etmektedir.

Dikkat ve özen yükümlülüğünün başka pozitif hukuk metinlerinde de yansımaları görmektediriz.

Örneğin;

- 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı **Türk Borçlar Kanununun** “Özen sorumluluğu”na ilişkin hükümleri (m. 66 vd., m. 417),
- 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı **Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun** sağlık hizmetlerinin icrasına ilişkin hükümleri,
- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı **Karayolları Trafik Kanununda** belirlenmiş olan trafik kuralları,

bizzat kendisine yönelik özen yükümlülüğünün ihlâlini esas alan görüş (STRATENWERTH, kn. 1097; İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 109, 142 vd., 152/153); haksızlık ve kusur ayırımını bir kenara itmektedir (ROXIN, Lehrbuch I, 24/51; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 112). Bu anlayış, 19. yüzyılda ileri sürülmüş olan ve haksızlık ile kusur arasındaki ayırımı bertaraf eden "emirler teorisi"ne dönüş mahiyeti arz etmektedir (eleştiri için bkz. ROXIN, Lehrbuch I, 24/52-58).

³²⁷ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 92, 95, 107, 109.

- 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı **İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun** iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümleri,
- 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı **İmar Kanununda** yer alan inşaat faaliyetinin icrasına ilişkin hükümler,
- 29.60.2001 tarihli ve 4708 sayılı **Yapı Denetimi Hakkında Kanunda** belirlenmiş olan yapı denetimine ilişkin kurallar,
- 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı **Maden Kanununda** yer alan maden üretim faaliyetinin icrasına ilişkin kurallar,

bir bütün olarak, aynı zamanda, kişilerin hayatına ve vücut bütünlüğüne yönelik dikkat ve özen yükümlülüğünü ifade etmektedirler.

Dikkat ve özen yükümlülüğünün kanundan kaynaklandığını söylemekle birlikte, bu yükümlülük çerçevesinde alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu her zaman pozitif hukuk metinleriyle belirlemek imkanı bulunmamaktadır.

Örneğin temizlik amacıyla bahçesindeki çalı ve çırpıyı bir araya toplayarak ateşe veren kişi, bu ateşin ormana veya bir eve sıçramaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu durumda ne tür tedbirin alınacağı pozitif hukuk metniyle belirlenmiş değildir. İcra edilen faaliyet sonucunda kişilerin veya toplumun ortak malvarlığı değerlerinin zarar görmemesi için müşterek hayat tecrübeleri itibarıyla gerekli olan tedbirlerin alınması gerekmektedir. Örneğin çalı ve çırpının yakılması suretiyle çıkan ateşin kontrol altında tutulması, yakma işi tamamlandıktan sonra, ateşin iyice söndürülmesi gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Günlük hayatımıza teknolojinin girmesiyle ve teknolojik gelişmeye orantılı olarak kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından uymamız gereken kuralların kapsamında artış meydana gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, günlük hayatımızı kolaylaştırdığı oranda kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike oluşturmaktadır. Buna rağmen, günlük hayatımızda teknolojik imkânlardan yararlanabilmesi için söz konusu tehlikeleri mümkün olduğunca asgariye indirmeye yönelik kurallar belirlenmiştir. Ancak bu kurallara riayet edilmesi koşuluyla kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından tehlikeli olan faaliyetlere izin verilebilmektedir³²⁸.

³²⁸ “Toplumsal yaşamda belli faaliyetlerde bulunan kimselerin başkalarına zarar vermemek için **birtakım önlemler** alması ve **bazı davranış kurallarına** uyma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu kurallar **toplum olarak yaşama zorunluluğundan doğabileceği** gibi, Devletin müdahalesiyle de ortaya çıkabilmektedir. Taksirli suç bu kuralların ihlal edilmesi sonucu belirir, fail tedbirli ve öngörülü davranmamış olduğu için cezalandırılır. Bu bakımdan sorumluluğun nedeni, öngörebilme imkân ve ödevinin varlığına rağmen sonuca iradi bir hareketle neden olmaktan kaynaklanmaktadır.

Taksirle gerçekleştirilen bazı eylemlerin suç olarak tanımlanıp cezaî yaptırıma bağlanmasıyla, insanların gittikçe yoğunlaşan ve karmaşık hale gelen toplum hayatı içinde daha dikkatli davranmalarının temin edilmesi amaçlanmaktadır. Kanun ve ortak hayat tecrübesinin sonucu olarak kendisine **toplum tarafından yüklenen dikkat ve özen yükümlülüğünü** ihlal eden ve bu hareketiyle öngörülebilir zararlı neticeye sebep olan kişinin taksirle işlenen suçlara ilişkin cezaî sorumluluğu benimsenmiştir”tir: **CGK, 18.11.2014**, E. 2013/12-38, K. 2014/493.

Bazı faaliyetler bağlamında dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde hangi somut tedbirlerin alınacağı da pozitif hukuk metinlerinde belirlenmektedir.

Örneğin karayolu motorlu taşıt trafiğinin hayatımıza girmesi sebebiyle belirlenmiş olan karayolu trafiğinde alınması gereken tedbirler, 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı **Karayolları Trafik Kanunu** ile bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Yönetmelikte³²⁹ açıkça belirlenmiştir.

Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak alınması gereken tedbirler, “**Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük**”te³³⁰ belirlenmiştir.

Bunların dışında, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı **İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu** hükümleriyle (m. 8, f. 2), bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama hususunda alınması gereken tedbirleri belirleme yetkisi, **işyeri hekimi**³³¹ ve **iş güvenliği uzmanına**³³² verilmiştir. Bu düzenleme karşısında, bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama bağlamında alınması gereken tedbirlerde işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı tarafından zaman içerisinde değişiklik yapılabilecektir³³³.

Önemle işaret etmemiz gerekir ki, iş kazasının meydana geldiği işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği bağlamında işverene terettüp eden bir yükümlülük ihlali söz konusu olduğu takdirde, bu kaza sonucu meydana gelen ölüm veya yaralanmalardan dolayı ceza hukuku bakımından sorumluluk için, yükümlülük ihlali ile kaza arasında illiyet bağının bulunması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, ölümlü veya yaralanmalı iş

³²⁹ 18 Temmuz 1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve zaman içinde değişikliklere maruz bırakılan **Karayolları Trafik Yönetmeliği** bu bağlamda göz önünde bulundurulması gereken bir pozitif hukuk metnidir.

³³⁰ RG: 22 Ekim 1984/18553.

³³¹ 6331 sayılı Kanunda, “**İşyeri hekimi**: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim” olarak tanımlanmıştır (m. 3, f. 1, bent 1).

³³² 6331 sayılı Kanunda, “**İş güvenliği uzmanı**: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen **müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman**” olarak tanımlanmıştır (m. 3, f. 1, bent f).

³³³ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**’nun 18.11.2014 tarihli ve E. 2014/12-179, K. 2014/499 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, S, kablo imalathanesinin sorumlu müdürüdür. K, S’nin isteği üzerine pres makinasını çalıştıran D’nin yanına gider ve D’nin uyarısına rağmen makinada oluşan plastik artıklarını temizlemek için elini uzatır. Bu sırada D’nin çalıştırma butonlarına basması üzerine K, elini makinaya sıkıştırır ve sağ el 3, 4 ve 5. parmakları kopar. Ceza Genel Kurulu’nun söz konusu Kararında, “... imalathane sorumlu müdürü olan S’nin, imalathanede işçi olarak çalışan K’ye, (kazanın meydana geldiği) pres makinasının çalışma prensipleri ile riskleri başta olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermediği, çalışmalarında yeterli denetim ve gözetim görevini yerine getirmediği, (bu suretle) ... dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranış (dışı ve) K’nin yaralanmasına” taksirle sebebiyet verdiği kabul edilmiştir.

Dikkat edilmelidir ki, bu kararda, sorumlu müdürün ceza hukuku sorumluluğunun dayanağını oluşturan yükümlülük ihlali kabul edilirken herhangi bir pozitif hukuk metnine atıfta bulunulmamıştır.

kazasının iş sağlığı ve güvenliği bağlamında bir yükümlülüğün ihlali sebebiyle meydana gelmiş olması gerekir. Bu itibarla, **iş sağlığı ve güvenliği bağlamında bir yükümlülük ihlal edilmiş olsa bile, iş kazası bu yükümlülük ihlali dışında başka bir sebeple meydana gelmiş ise, ihlal edilen yükümlülüğün terettüp ettiği kişi bu sebeple ceza hukuku bakımından sorumlu tutulamaz**³³⁴.

Ayrıca belirtelim ki, somut olayın özellikleri itibarıyla netice objektif olarak öngörülebilir nitelikte olmakla birlikte, özellikle kolektif bir faaliyetin icra edildiği durumlarda bu neticenin oluşumundan ceza hukuku bakımından kimin sorumlu tutulacağı, bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çok sayıda kişinin kolektif katılımını gerekli kılan faaliyetlerde, faaliyet bağlamında her bir kişinin görevini ayrı ayrı belirlemek gerekir. Ancak böyle bir belirleme yapıldıktan sonra, taksirle sebebiyet verilen ölüm veya yaralanmadan sorumluluk cihetine gidilebilir. Aksi takdirde, kolektif sorumluluğun yolu açılmış olur. Oysa ceza hukukunda **kusur esasına dayalı şahsi sorumluluk** söz konusudur. Nitekim Türk Ceza Kanununun 22. maddesinin beşinci fıkrasında taksirli suçlarda şahsi sorumluluk esası hüküm altına alınmıştır:

“Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.”

³³⁴ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **02.06.2015** tarihli ve E. 2013/12-623, K. 2015/187 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, gündüz saat 16.30 sıralarında, meskun mahalde, açık havada, bölünmemiş, iki yönlü, eğimsiz, virajlı, toplam genişliği 7 metre olan yolda sevk ve idaresindeki otomobili ile seyir halinde bulunan Ekrem’in, gidiş istikametine göre yolun sola virajlı bölümüne geldiği sırada şerit ihlali yaparak karşı şeride girerek, karşı yönden gelen **ehliyet-siz sürücü** Bülent’in kullandığı otomobil ile çarpışması neticesinde meydana gelen kazada Bülent’in kullandığı arabada bulunan eşi Türkan ile 8 aylık oğlu Ramazan, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanırlar.

Trafik kazası tespit tutanağında, Ekrem’in şerit ihlali yaptığı ve virajlı yola kontrolsüz girdiği; diğer sürücü Bülent’in ise normal şeridinde dönüş yaptığı ve kazaya etken bir davranışının bulunmadığı tespit ve değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Keza, keşif sonrasında düzenlenen bilirkişi raporunda; Ekrem’in, virajlı yolda karşı yönden gelen aracın kullandığı yol bölümüne girdiği ve şerit ihlali yaptığı için, “asli kusurlu” olduğu; ehliyet-siz olan diğer sürücü Bülent’in ise, kendi yol bölümünü takip ederek dönüş yaptığı için, kazaya etken bir kusurunun bulunmadığı tespit ve değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Bülent savunmasında, oğlu Ramazan’ın hasta olması nedeniyle eşiyle birlikte sevk ve idaresinde bulunan otomobille hastaneye gittikleri sırada karşısına Ekrem’in sevk ve idaresinde bulunan otomobilin aniden çıktığını, kafa kafaya çarpıştıklarını beyan etmiştir.

Ekrem ise savunmasında, sevk ve idaresinde bulunan araçla evine gittiğini, kazanın meydana geldiği sokağa gireceği sırada karşı yönden gelen aracın hızlı bir şekilde yola çıkması nedeniyle kazanın meydana geldiğini, suçlamayı kabul etmediğini, karşı tarafın zararını karşılamayacağını, karşı taraftaki araç sürücüsünün ehliyet-siz olduğunu beyan etmiştir.

Bu olayda, sürücü belgesi olmayan Bülent, meydana gelen trafik kazası sebebiyle ceza hukuku bakımından sorumlu tutulmuş değildir. Çünkü bu olayda, Bülent’in sürücü belgesinin olmadan araç kullanması ile meydana gelen trafik kazasının oluşumu arasında nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır.

Bu hükmün gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiyle sorumlu tutulur. Taksirli suçun kanuni tanımında belirlenen netice birden fazla kişinin karşılıklı olarak işledikleri taksirli fiiller sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Örneğin bir trafik kazasında sürücü ile yaya veya her iki sürücü de taksirle hareket etmiş olabilir. Bu gibi durumlarda neticenin oluşumu açısından her kişinin taksirli fiili dolayısıyla kusurluluğu bir diğerinden bağımsız olarak belirlenmelidir.

Aynı şekilde birden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ameliyatın ölüm veya sakatlıkla sonuçlanması durumunda, ameliyata katılan kişiler müştereken hareket etmektedirler. Ancak tıbbın gereklerine aykırılık dolayısıyla ölüm veya sakatlıkla sonuçlanan bu ameliyatta işlenen taksirli suçun işlenişi açısından suça iştirak kuralları uygulanamaz. Kanunun suça iştirake ilişkin hükümleri, kasten işlenen suçlarda suçun işlenişine iştirak eden kişilerin sorumluluk statülerini belirlemektedir. Birden fazla kişinin katılımıyla yapılan ameliyat sırasında meydana gelen ölüm veya sakatlık neticeleri bakımından her bir kişinin sorumluluğu kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmelidir. Bu tespit-te diğer kişilerin kusurlu olup olmadığı hususu dikkate alınamaz.”

Yukarıda açıklandığı gibi, taksirli suçun söz konusu olduğu durumlarda, mutlaka bir yükümlülük ihlal edilmiş olmalıdır. Ayrıca taksirli suç nedeniyle sorumluluk için, ihlal edilen yükümlülüğün kime terettüp ettiğinin, kimin hangi yükümlülüğü ihlal ettiğinin açık bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede somut olayda, ölüm veya yaralanma sonucunu doğuran;

- a) hangi yükümlülüğün/yükümlülüklerin ihlâl edilmiş olduğunun,
 - b) bu yükümlülüğün/yükümlülüklerin kime/kimlere terettüp ettiğinin,
- açık bir şekilde belirlenmesi gerekir.

I. Bir iş kazasının meydana gelmesi halinde, ilk yapılması gereken, bu işyerinde veya icra edilen iş bağlamında, kazanın meydana geldiği tarih itibarıyla mer’i olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin neler olduğunu belirlemektir.

Yukarıda açıklandığı gibi, 6331 sayılı **İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu** hükümlerine (m. 8, f. 2) göre, bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama hususunda alınması gereken tedbirlerin neler olduğu **işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı** tarafından belirlenmektedir.

Belirlenen tedbirlerin gereğini yapmak, **işverene**³³⁵ terettüp eden bir görevdir (6331 s. Kanun, m. 4). Belirlenen tedbirler, **işverene** yazılı olarak bildirilecektir (6331 s. Kanun, m. 8, f. 2).

³³⁵ 6331 sayılı Kanunda, “**İşveren**: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır (m. 3, f. 1, bent g).

Kişilerin ölümü veya yaralanması ile sonuçlanan bir iş kazasında, iş koluna ilişkin mevzuat hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, kazanın meydana geldiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından alınması gereken tedbirler bağlamında hangi yükümlülüğün veya yükümlülüklerin kimler tarafından ihlal edildiğinin açık bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu suretle, meydana gelen ölüm veya yaralanmadan dolayı kimin veya kimlerin ceza hukuku bakımından sorumlu tutulabileceğinin tayini mümkün olabilir. Aksi takdirde, ceza hukuku sorumluluğunda paçal bir uygulamanın yolu açılmış olur. Ancak bu kabul bir uygulama, kusura dayalı ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralı ile çelişir.

6331 s. Kanuna göre, iş sağlığı güvenliği bakımından gerekli tedbirleri alma hususundaki asli görev, işverene terettüp etmektedir (m. 4).

İşyeri sahibinin şirket gibi tüzel kişi olması halinde, yöneticiler arasında işbölümü çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma hususunda kimin veya kimlerin görevlendirildiği belirlenmiş ise, sorumluların belirlenmesi bağlamında bir sorun olmaz.

Ancak çoğunlukla, yöneticiler arasında işbölümü çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma hususunda kimin veya kimlerin görevlendirildiği belirlenmemektedir. Bu gibi durumlarda, meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı iş kazasından dolayı kimin veya kimlerin ceza hukuku bakımından sorumlu tutulması gerektiği bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanaatimizce bu gibi durumlarda işyerindeki üretim faaliyetinin sevk ve idaresindeki fiili durumu göz önünde bulundurarak, meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı iş kazasından dolayı kimin veya kimlerin ceza hukuku bakımından sorumlu tutulması gerektiğini belirlemek gerekir.

II. Maden çıkarma faaliyeti, “İşletme İzni”nin³³⁶ verilmesine ve “İşletme Ruhsatı”nın³³⁷ düzenlenmesine bağlı olarak icra edilebilir (4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı **Maden Kanunu, m. 7)³³⁸.**

İşletme Ruhsatı sahibinin, maden işletme faaliyetinde bulunabilmesi için, belirli bir tecrübeye sahip bir veya birkaç maden mühendisini (zaman içerisinde aldığı

³³⁶ 3213 sayılı Maden Kanununda, “**İşletme İzni**: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin” olarak tanımlanmıştır (m. 3).

³³⁷ 3213 sayılı Maden Kanununda, “**İşletme Ruhsatı**: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi” olarak tanımlanmıştır (m. 3).

³³⁸ Maden üretim faaliyeti çerçevesinde iş güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin belirlenmesi bağlamında,

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan **Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği** (RG: 06 Kasım 2010/27751),

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan **Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği** (RG: 19 Eylül 2013/28770),

hükümlerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

isim itibarıyla, “fenni”, “teknik” veya “daimi”) nezaretçi sıfatıyla görevlendirilmesi gerekmektedir³³⁹.

Kanun, maden işletme faaliyetinin icra edildiği alanlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almakla, işletmede nezaretçi olarak istihdam edilen maden mühendisini görevli, yetkili ve sorumlu kılmıştır³⁴⁰.

Nezaretçi, maden işletmesinde “3213 sayılı Maden Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde ve yönetmeliklerinde yer alan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.” (Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, m. 107).

“... nezaretçi, nezaret görevini 3213 sayılı Maden Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında yürütür. ... nezaretçi, ruhsat sahasındaki faaliyet ve üretimleri ... denetlemek, tespitlerini ve önerilerini ... nezaretçi defterine not etmek zorundadır. İşyerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli bir durumun varlığını tespit etmesi ve hemen tedbir alınmasının mümkün olmadığını belirlemesi durumunda, işletme faaliyetini tedbir alınmaya kadar durdurma yetkisini kullanarak ilgili kuruluşlara bildirir.” (Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, m. 111, bent b).

“... nezaretçi, atanmış olduğu işyerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri belirler. Bunları ... noter onaylı “... Nezaretçi Defteri” ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların, öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunların yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.” (Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, m. 111, bent b).

Şayet nezaretçi olarak görevlendirilen maden mühendisi işletmede iş sağlığı ve güvenliği bağlamında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak gördüğü eksiklikleri noter tasdikli “Nezaretçi Defteri”ne rapor ederek İşletme Ruhsatı sahibine bildirmiş ise, bu tedbirlere riayetsizlik sonucu oluşan iş kazasından dolayı İşletme Ruhsatı sahibi gerçek kişinin veya şirketin yetkilisi konumundaki gerçek kişilerin ceza hukuku sorumluluğu yoluna gidilebilir.

³³⁹ “Kaynak tuzları hariç olmak üzere maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunludur. Daimi nezaretçi ile vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi ve görevlendirilecek diğer mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları, atanma usul ve esasları, eğitimi, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” (3213 sayılı Maden Kanunu, m. 31, f. 1).

³⁴⁰ 3213 sayılı Maden Kanunu, m. 10, f. 6; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan **Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği** (RG: 06 Kasım 2010/27751), m. 107, m. 111, bent b.

Hatta bazı durumlarda, İşletme Ruhsatı sahibi gerçek kişinin veya şirketin yetkilisi konumundaki gerçek kişilerin yanı sıra, nezaretçilerin de ceza hukuku bakımından sorumluluğu yoluna gidilebilir. Örneğin işletmede maden üretim faaliyetiyle ilgili teknik bir eksiklik veya yanlışlık olduğu bilinmesine rağmen, bu eksiklik veya yanlışlığın nezaretçi defterine kaydedilmemiş olması, bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini sağlamaya yönelik olarak üretim faaliyetinin durdurulmamış olması, her ilgilinin kendisine terettüp eden yükümlülüğü yerine getirmemesi sebebiyle sorumluluğunu gerektirmektedir.

III. İnşai faaliyet, bir bina inşası, ancak fenni mes'ulün gözetim ve denetimi altında icra edilebilir (3194 s. İmar Kanunu, m. 28, f. 2, 3).

Bir bina, meydana gelen depremde çöker ve enkaz altında çok sayıda kişi ölür. Yapılan bilirkişi incelemesinde,

- a) binanın statik projesinin tekniğine uygun yapılmadığı,
 - b) binanın inşasında kullanılan demirin evsafının uygun olmadığı,
 - c) demir bağlantılarının tekniğine uygun olarak yapılmadığı,
 - ç) binanın inşasında kullanılan betonun tekniğine uygun olmadığı,
- tespit edilir.

Bütün bu hususlar, ilgili kişilerin depremin de etkisiyle çöken binanın enkazı altında çok sayıda kişinin ölümünden dolayı sorumluluğunu gerektirir.

Binanın statik projesinde hata bulunması, bu hatalı projeyi hazırlayan müellif mimar ve mühendislerin ceza hukuku bakımından sorumluluğunu gerektirir (3194 s. İmar Kanunu, m. 28, f. 1; m. 38, f. 2).

Binanın inşası bağlamındaki teknik hatalar dolayısıyla sorumluluk, özellik arz etmektedir.

Şayet bir binanın inşası, gerekli bilgi birikimine sahip olduğu resmen belgeli bir mühendisin sorumluluğunda, gözetim ve denetimi altında gerçekleştiriliyorsa, inşası bağlamındaki teknik hatalar sonucu çöken binanın enkazı altında kalan kişilerin ölüm veya yaralanmasından bu teknik kişiyi sorumlu tutmak gerekir (3194 s. İmar Kanunu, m. 28, f. 2). Bu durumda bina sahibini sorumlu tutmamak gerekir. Çünkü bina sahibi, inşaa işinin gözetim ve denetimini gerekli bilgi birikimine sahip olduğu resmen belgeli bir mühendise tevdi etmekle, hukuken kendisine terettüp eden yükümlülüğe uygun davranmıştır (3194 s. İmar Kanunu, m. 28, f. 11).

Ancak, gerekli bilgi birikimine sahip olduğu resmen belgeli bir mühendisin gözetim ve denetimi olmaksızın girilen inşai faaliyet sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet edilmemesi sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan inşaat sahibini sorumlu tutmak gerekir. Çünkü, yukarıda da belir-

tildiği gibi, bir bina inşası ancak **fenni mes'ulün** gözetim ve denetimi altında icra edilebilir (3194 s. İmar Kanunu, m. 28, f. 2, 3). Fenni mes'ul belirlenmezsiniz, fenni mes'ulün gözetim ve denetimi olmaksızın, tekniğine aykırı olarak, hatalı olarak inşa edilen binanın depremin de etkisiyle çökmesi sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan bina sahibini sorumlu tutmak gerekir.

Fenni mes'ulün gözetim ve denetimi altında inşa edilen ve bilahare depremin de etkisiyle çöken binanın enkazı altında kalan kişilerin ölümünden veya yaralanmasından, fenni mes'ulü ceza hukuku bakımından sorumlu tutmak gerekir.

Ancak, fenni mes'ulün iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına yönelik taleplerine ve mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılarına rağmen, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle meydana gelen ölüm veya yaralanmalardan işveren konumundaki şirketin yönetim organında görev yapan ve bu talep ve uyarıların muhatabı olan kişi veya kişileri ceza hukuku bakımından sorumlu tutmak gerekir³⁴¹.

³⁴¹ Yargıtay **12. Ceza Dairesi'nin 27.06.2014** tarihli ve E. 2014/8620, K. 2014/16069 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, “**23 Ekim 2011** tarihinde yerel saatle 13.41 sıralarında Van şehir merkezinin yaklaşık 20 km. kuzeyinde, ... değişik kuruluşlara göre şiddeti 7.1 ila 7.3 arasında değişen yıkıcı bir deprem meydana gelmiş, Van İl merkezinin yanı sıra Erciş İlçesi ve civar köylerde önemli hasara yol açmıştır. Depremin birinci haftasında, bölgede büyüklüğü 4.0-4.9 arasında toplam 114 deprem meydana gelmiş olup; şiddeti 5.0'dan büyük olan deprem sayısı ise 7'dir. İlk deprem sonrası artçı şoklar devam ederken, **9 Kasım 2011** tarihinde şiddeti 5.7 olan ve farklı bir faydan kaynaklanan ikinci bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremin merkez üssünün Van İl merkezinin güney batısında kalan Edremit ilçesi olduğu anlaşılmıştır.

Sanığın sahibi ve işleteni olduğu Bayram Otel bu (ikinci) **depremde** yıkılarak çökmüş, göçük ve enkaz altında kalan AY, AKG, GY, AM, MÇ, ÇOG, HB, TA, ET, AÖ, ÖE, SK, SY, EA, RY, OY, CE, RK, RO, SK, BÖ, TK, RA ve JM ölmüştür. Toplam 24 kişinin öldüğü, katılan MD'nin ise yaralandığı olayın yargılaması sırasında alınan ve hükme esas tutulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden kurulu Nisan 2012 tarihli bilirkişi raporunda da işaret edildiği üzere, otelin 19/09/2003 tarihinden itibaren işletmecisi olan “sanığın işlettiği otel binasının 1964 yılında inşa edilen, 1978, 1998 ve 2007 deprem yönetmeliklerine göre güçlendirilmemiş eski bir bina olduğu, otele sonradan ilave edilen kısımların bulunduğu, proje dışı yapılan ek kısımların binalarda deprem güvenliği açısından son derece tehlike oluşturduğunun bildirildiği, otel binasının babası tarafından inşa ettirilmiş olması nedeniyle sanığın, otelin eski bir bina olduğu, sonradan yapılan esaslı değişikliklerden ve otele ek yük yükleyen çelik konstrüksiyon çatıdan haberdar olduğu, otel binasının dış cephesinin amerikasyding denilen bir kaplama malzemesi ile kaplanarak yenilenmesi, kolonların alçıpanlarla giydirilmiş olması, tavanlara asma tavan ve alçıpan kartonpiyer uygulamalarının yapılması nedeniyle dışarıdan yapılacak basit bir gözlemlerle çatlakların görünmeyeceği ve hasar tespiti yapılmasının mümkün olmadığı hususunun sanık tarafından bildirildiği, kaplama yapılmış binalarda kaplamanın altına bakılarak, matkaplarla bu kaplamalar açılarak sıvalarda, kolonlarda çatlaklar olup olmadığının incelenmesi, taşıyıcı sistemden numuneler alınıp test edilmesi gerektiği, sanığın kesin hasar tespit raporu hazırlanması için inceleme yaptırmak, işin uzmanlarından görüş almak, bilimsel analizler yaptırmak bir yana, gözleme dayalı olarak hazırlanan ön hasar tespit çalışmasını dahi yaptırmadan, 120 kişilik barınma kapasitesi olan, toplu olarak yaşayan insan sayısının fazla olduğu eski bir binayı, **23.10.2011** tarihinde gerçekleşen **7,2 büyüklüğündeki depremden sonra ara vermeksizin işletmeye devam ettiği**, sanığın Bayram Otel binasının evveliyatını çok iyi bilen ve uzun yıl-

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, deprem olgusu, binanın hatalı projelendirilmesiyle ya da tekniğine aykırı olarak inşa edilmesiyle, enkaz altında kalan kişilerin ölümü veya yaralanması arasındaki nedensellik bağını kesmez ve ortadan kaldırmaz.

B. Taksirli Haksızlık ve Netice İlişkisi

Yukarıda bulunduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunmakla, bir haksızlık gerçekleştirilmektedir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranış neticesinde bir insan ölmüş veya yaralanmış ya da bir başkasının malvarlığına zarar verilmiş olabilir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranış sonucunda meydana gelen bu neticeler, taksirli haksızlığın niteliğinde bir değişiklik meydana getirmez. Bu neticeler, kişiye uygulanacak yaptırımlar açısından bir farklılık oluşturabilir. Şöyle ki; dikkat ve özen yükümlülüğünün bu tezahür şekli olan trafikle alakalı kurallara salt aykırı davranış, bir

lardır da bu binada faaliyet gösteren otelin işletmeciliğini yapan tecrübeli bir tacir olduğu, binanın eski olması, sonradan yapılan esaslı değişikliklerin binaya ek yük yükleme, yenileme faaliyeti kapsamında yapılan kaplama işlemi nedeniyle duvar ve kolonlardaki çatlakların dışarıdan gözle bakılarak tespit edilememesi nedeniyle binanın 23.10.2011 tarihinde gerçekleşen depremde hasar görmüş olabileceğinin, ileride yaşanacak herhangi bir depremde, otel binasının daha önce aldığı hasar nedeniyle yıkılabileceğinin sanık tarafından da öngörülmesi gereken bir husus olduğu, otelin alt katında faaliyet gösteren Albaraka Türk Bankası için hazırlanmış, gözleme dayalı ön hasar tespit raporunda güçlendirme projesi ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerektiği, binanın risk taşıdığı belirtilmesine rağmen, sanığın bir daha deprem yaşanmayacağına inanması, geçmiş deneyimlerinin şanslı sonuçlanması gibi nedenlerle bu riski göze aldığı ve oteli, kesin hasar tespit çalışmaları sonuçlandırılıp güvenli olduğu anlaşılan kadar işletmeye ara vermesi gerekirken, depreme dayanıklılık testi yaptırmak bir yana ön hasar tespit çalışması dahi yaptırmadan ve 23.10.2011 tarihindeki depremden sonra hiç ara vermeden işletmeye devam ettiği anlaşıldığından, sanığın meydana gelen neticeyi 5237 sayılı TCK'nın 22/3. maddesi kapsamında öngördüğünün, dolayısıyla da olayda (Esas mahkemesi tarafından) bilinçli taksir halinin bulunduğu" kabul edilmesinde (Dairece) bir isabetsizlik görülmemiştir.

...

(Ancak,) ... Bayram Otel işletmecisi olan sanığın, ... Van İlının 1. derece deprem bölgesi olmasına rağmen statik projesi, statik hesap raporu ve zemin raporu olmaksızın, 1964 yılında konut olarak, inşaat tekniğine ve mevzuatına aykırı şekilde, ... ölmüş bulunan babası ... tarafından inşa ettirilen, 1969 yılından itibaren otel olarak işletilen bodrum, 5 normal kat ve üstü çelik konstrüksiyon çatı sistemi kapatılmış bulunan kaçak teras kattan oluşan otel binasını, söz konusu eksikliklerini bilmesine rağmen 1975, 1998 ve 2007 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkisi ve olanağı bulunmasına rağmen güçlendirmede, otel binasının özellikle yaşı ve bulunduğu bölge itibarıyla yüksek riskli deprem kuşağında yer almasına rağmen, depremden bir yıl kadar önce yaptırdığı ... tadilatın, otel binasının taşıyıcı sistemi ile değil, otelin iç ve dış dizaynı ile ilgili olduğu nazara alındığında, sanığın kusurunun ilk deprem sonrası gerekli inceleme ve hasar tespiti yaptırmamakla, bu tespitler yapılana kadar oteli kullanmamakla sınırlı olmadığı, inşaat ve tadilatlarında eksiklikleri bulunduğunu bildiği eski otel binasının en azından 2007 deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmemesi, binanın taşıyıcı sisteminin güçlendirilmemesi sebebiyle de kusurlu olduğunun nazara alınıp, olay nedeniyle 24 kişinin öldüğü değerlendirilerek; (TCK, m. 85, f. 2'deki) iki sınır arasında temel ceza belirlenirken adalet, hakkaniyet ve nesafet kurallarına uygun makul ve azami hadde yakın bir cezaya hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, 10 yıl temel ceza tayini," hukuka aykırı bulunarak hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

idari yaptırım uygulanmasını gerekli kılabilir. Bu durumda yaptırım uygulanması için dikkat ve özen yükümlülüğüne kasten aykırı davranmak yeterlidir.

İzlenen suç siyasetine istinaden dikkat ve özen yükümlülüğüne salt aykırı davranış, suç olarak da tavsif edilmiş olabilir. Bu durumda ceza yaptırımı uygulanması için dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunmakla örneğin “*başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike*”ye sebebiyet verilmesi yeterli olmalıdır; fakat, suçun oluşması için, dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâlinin yanı sıra, ayrıca bir şahsın yaralanması veya ölmesi gibi bir neticenin meydana gelmesi zorunlu değildir. Örneğin yeni TCK’nın 171. maddesinde, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, genel güvenliğin tehlikeye sokan belli fiillerin taksirle işlenmesi de, suç oluşturmaktadır. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekir (objektif cezalandırılabilme şartı olarak somut tehlikenin gerçekleşmesi)³⁴².

Başlı başına bir haksızlık oluşturan dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranış neticesinde bir kişinin ölmesi veya yaralanması ya da bir başkasının malvarlığına zarar verilmesi halinde; söz konusu haksızlığın niteliğinde bir değişiklik meydana gelmemektedir.

Ancak, Kanun, dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâlinin yanı sıra ayrıca bir *neticenin gerçekleşmesi halinde* taksirli suçun oluşacağını kabul etmektedir (m. 22, f. 2). Bu nedenle, bazı yazarlar taksirli suçlarda neticenin meydana gelmesini bir objektif cezalandırılabilme şartı olarak kabul ederler. Fakat, genellikle kabul edildiği üzere; hukuken tasvip edilmeyen neticenin meydana gelmesi taksirli suçun bir unsurunu oluşturmaktadır³⁴³.

Bu bağlamda ifade etmek gerekir ki; bu netice, dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâli sonucu olarak gerçekleşmelidir³⁴⁴. Somut olayda gerçekleşen netice ile failin dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâli niteliğindeki davranışı arasında

³⁴² TCK’da taksirle işlenebilen soyut tehlike suçları da mevcuttur: Savaş zamanında yükümlülüklerin taksirle yerine getirilmemesi (m. 322, f. 2), Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgilerin taksirle açıklanması (m. 329, f. 3), açıklanması yasaklanan veya niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin taksirle açıklanması (m. 336, f. 3), bu suçlara örnek olarak gösterilebilir.

³⁴³ İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 163; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 2. bası, sh. 252; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 173; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, İkinci Bölüm, §1, III, 3, E.

³⁴⁴ «Hadisenin maznunun ehliyetli kamyon sevk ve idare etmesinden ve onun fiilinden ileri gelmeyip gayri fenni şartlarla yapılan yol duvarının çökmesi neticesi husule geldiği ve maznunun tedbirsizliği ve dikkatsizliği bulunmadığı bilirdikşilerin fenni mütalaalarından anlaşıldığı ve şu suretle maznunun ehliyetli oluşu ile netice arasında alaka ve irtibat mevcut olmadığı halde mücerret ehliyetli sebep ile maznunun mahkumiyeti cihetine gidilmesi bozmayı gerektirmiştir.»: 4. CD, 11.6.1954, 2948/6028 (Keskin, sh. 35).

illiyet bağının bulunması gerekir³⁴⁵. Bu illiyet bağlantısı mevcut değilse veya netice dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali sonucu olarak gerçekleşmemiş ise, artık taksirden bahsetmek mümkün olmayacaktır^{346,347,348}.

³⁴⁵ İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 168 vd.; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 974; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, İkinci Bölüm, §1, III, 3, E, d; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh. 322; CENTEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 323.

Yargıtay'a göre, icrai veya ihmali davranış ayırımı yapmaksızın, taksirli suçlarda failin dikkatsiz ve özensiz fiili ile meydana gelen netice arasında illiyet bağının bulunması gerekir. "*Taksirli suçlarda nedensellik bağının varlığının kabulü için, failin hareketinden bağımsız bir etkenin sonuca tek başına neden olmaması gerekir.*": CGK, **8.7.2008**, E. 2008/1-99, K. 2008/185; CGK, **20.5.2008**, E. 2008/9-51, K. 2008/117; CGK, **16.10.2007**, E. 2007/9-192, K. 2007/211.

³⁴⁶ Doktrinde failin gerekli dikkat ve özeni göstermiş olması halinde de netice meydana gelecekti diyebileceğimiz hallerde taksirden söz edilemeyeceği fikri ileri sürülmüştür (ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 337 vd.). Kanaatimizce, objektif özen yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen netice arasında illiyet bağının varlığı halinde, faraziyelerden hareketle sorumluluktan sarfınazar edilemez. Bu itibarla, **ülkemizde gerçekleşen depremlerde yıkılan binalarla ilgili olarak ceza hukuku sorumluluğunun tayini açısından düzenlenmiş olan bazı "bilirkişi" raporlarında ileri sürülen aksi yöndeki düşünce doğru değildir.**

³⁴⁷ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu'nun 11.3.2008** tarihli ve E. 2007/9-275, K. 2008/49 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; 13.4.2006 günü 14.30 sıralarında Yeniçağa ilçesinden Mengen yönüne doğru Devlet karayolu üzerinde gitmekte olan bir kargo firmasına ait kamyonetin sol arka tekerleğinin bijonları seyir sırasında kesilir; bu nedenle tekerlek yerinde çıkar. Araç sürücüsü, arızalı aracı karayolunun sağına, kısmen bankete kısmen de yola isabet edecek biçimde park eder; aracın 17 metre gerisine reflektör ve stepne koyarak güvenlik önlemi alır ve jandarmaya haber vermek üzere oradan ayrılır. Bundan kısa bir süre sonra aynı yöne doğru arka arkaya belirli mesafelerle seyretmekte olan üç araçtan öndeki kamyonun sağda parkeden arızalı aracı görerek fren yapması üzerine arkasından seyreden kamyonun sürücüsü de fren yaparak hızını azaltır. Konvoyun sonundaki tankeri kullanmakta olan SS de öndeki aracın aniden fren yaptığını görünce frene basar. Ancak, sıvı yüklü tankerin dengesi bozulur ve SS aracın kontrolünü kaybeder. Tanker, öndeki kamyonun sol arka kısmına çarptıktan sonra sol şeride geçerek karşı yönden gelmekte olan otomobille çarpışır. Otomobil sürücüsü SMR ile otomobilde bulunan GAA ölür, HÖ ise yaralanır.

Kazanın meydana geldiği mıntıkada çift şeritli ve asfalt kaplama olan yolun genişliği 7,5 metre, yol kenarındaki banketlerin her birinin genişliği ise 130 santimetredir. Olay sırasında görüş açık ve zemin kurudur.

Bu olayla ilgili olarak hakkında açılan kamu davasında Esas Mahkemesi, SS'nin **taksirle** birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle, 5237 s. TCK'nın 85. maddesinin ikinci fıkrası ve 62. maddesi uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53. maddesinin altıncı fıkrasına göre cezasının infazından sonra sürücü belgesinin bir yıl süreyle geri alınmasına hükmetmiştir.

Temyiz üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kararı onamıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise onama kararına itiraz etmiştir. İtiraz üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıda özetlemiş olduğumuz gerekçe ile, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar vermiştir:

SS'nin "*önünde seyreden aracın ani fren yapması üzerine kendisinin de fren tedbirine başvurmaya rağmen kullandığı tankerdeki sıvı yükün etkisiyle duramayıp aracıyla öndeki aracın sol arka köşesine vurması ve kontrolden çıkarak diğer şeride geçtiğinde karşı yönden gelen araçla çarpışması biçiminde gelişen olayda, neticeyi öngöremeyen failin sorumluluğu taksir düzeyindedir. Olayda bilinçli taksirin öngörme koşulu gerçekleşmemiştir.*"

SS'nin bu olayda hangi sebeple taksirli davrandığı ve kusurlu bulunduğu, diğer sürücülerin herhangi bir trafik kuralını ihlal edip etmediği ve kusurlu olup olmadığı tartışılmamıştır. Kararda, soyut bir

Yargıtay, 765 s. TCK'nın yürürlükte olduğu dönemdeki pek çok kararında, aslında herhangi bir ilgisinin olmamasına rağmen, taksirle ilgili meseleleri illiyet bağlantısıyla açıklamaya çalışmıştı^{349, 350}.

şekilde, SS'nin bilinçsiz taksirle hareket ettiği kabul edilmiştir. Bu nedenle söz konusu kararın, taksirle işlenen suçlarla ilgili olarak hüküm kurarken yol gösterici olma özelliği bulunmamaktadır.

³⁴⁸ Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 07.05.2015 tarihli ve E. 2015/2180, K. 2015/7599 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, makat bölgesinden duyduğu rahatsızlık sebebiyle özel bir hastaneye başvuran M, hastanede Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan TÜ tarafından muayene edilir. Yapılan muayene sonucu "Anal fissür + peranal fistül" tanısı konulan hastaya önce antibiyotik tedavisi uygulanır, devamında ise cerrahi müdahalede bulunulur. Ancak, tıbbi şifa ile taburcu edilen hasta, ilerleyen dönemlerde operasyon bölgesinde ağrı-akıntı şikayeti ile birden çok kez TÜ'ye müracaat eder. TÜ, hastaya değişik antibiyotik tedavisi uygular ve sıcak banyo tedavisi tavsiyesinde bulunur. Ancak, şikayetleri devam eden hasta başka bir sağlık merkezine müracaat eder. Bu sağlık kuruluşunda yapılan muayenede hastaya "squamoz hücreli rektum kanseri" teşhisi konulur. Bunun üzerine hasta M, TÜ hakkında doğru teşhis ve tedavide bulunmadığı iddiası ile şikayetçi olur.

Bu olayla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun 04.03.2009 tarih 2041 sayılı kararında TÜ'nün uygulamasının tıp kurallarına uygun olmadığı belirtilmiştir.

Yüksek Sağlık Şurasının 08-09 Kasım 2012 tarih 13189 sayılı kararında ise, TÜ'nün tanıda "kusu-runun" bulunduğu ve bu nedenle doğru tanının ve tedavinin geciktiği, ancak beş aylık gecikmenin hastanın tedavisine ne oranda olumsuz etkilediğinin net olarak belirlenemeyeceği belirtilmiştir.

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun 20.11.2013 tarih 2013/97524/12604 sayılı raporunda ise, müştekinin rektum kanserinin geç teşhis edilmesi yönünde tıbbi standartlardan sapma olarak değerlendirilecek tıbbi kusur ya da ihmal tespit edilmediği belirtilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Genel Kurulunun 23.05.2013 tarih 244 sayılı raporunda da; TÜ'nün aynı hal ve şartlarda göstermesi gereken özeni gösterdiği, rektum kanserinin geç teşhis edilmesi yönünden tıbbi standartlardan sapma olarak nitelendirilebilecek tıbbi kusur ya da ihmalin tespit edilmediği belirtilmiştir.

Esas Mahkemesi bu olayda taksirinin bulunmadığı gerekçesiyle TÜ hakkında beraat kararı vermiştir.

Buna karşılık 12. Ceza Dairesi de, aşağıda özetlenen gerekçe ile bu kararı onar:

Taksirle yaralama suçunun oluşabilmesi için fiil ile netice arasında nedensellik bağının bulunması gerekir. TÜ'ye yöneltilen suçlama, operasyon öncesi eksik inceleme yapması ve operasyon sonucu şikayetleri devam eden hastayı bir üst merkeze sevkini yapmamasıdır. Oysa M, TÜ'nün eylemi sonucu kanser hastalığına yakalanmamıştır. Bu gecikme sebebiyle hastalığın ileri bir aşamaya geçtiğine dair delil ve iddia da bulunmamaktadır. Bu durumda, TÜ'nün fiili ancak "görevi ihmal" kapsamında değerlendirilebilir. Ancak, özel bir hastanede çalışan ve memur olmayan sanık için ise memurlara özgü suç olan "görevi ihmal" suçu oluşamaz. Bu durumda TÜ'nün ancak "hukuki sorumluluğu" yoluna gidilebilir.

³⁴⁹ «Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme ve yaralamaya sebep olmak suçundan sanık M.nin, TCK'nın 455/2-son maddesi gereğince 2 yıl hapis ve 5.000 lira ağır para cezasıyla tecziyesine ilişkin hükmü, Özel Daire:

"Dava konusu olayın; sanığın icarında ve mesuliyeti altındaki dükkân önündeki kaldırımda bulunan ve dükkâna ait hemzemin kuyuya gece vakti kaldırımda ana-baba ve küçük kardeşleri ile birlikte yürüyen 1971 doğumlu Alev'in düşmesinden -ki, bu düşme sonucu yaralı olarak kurtarılmıştır- bu düşmeyi fark eden annesi T.nin bağırması üzerine baba A.nın kızını kuyudan kurtarmak maksadıyla iradî olarak kuyuya atladığında, başını kuyunun kenar veya duvarlarına çarparak saçlı derinin arka kısmında husule gelen çöküntü yaptığı, koma halinde suya düşüp kafa travması ve suda boğulmadan ölmesinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Aslında bu kararlara konu teşkil eden olaylarda mesele, illiyet bağlantısının varlığı ile ilgili değildir. Bu olaylarda sorun, esasen dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket eden kişinin, tasvip edilmeyen neticenin meydana gelişinden dolayı sorumlu tutulup tutulmayacağıdır.

Bu oluşa göre küçük Alev'in yaralanmasının ve baba A'nın ölümünün iki ayrı safhada gerçekleşen iki ayrı olay olarak nitelenmesi icabeder.

(Bu itibarla;) 1- Birinci safhada meydana gelen küçük Alev'in yaralanmasından ibaret olayın TCK'nın 459. maddesine uyduğu; ikinci safhada baba A'nın ölümü ile neticelenen olayın ise müstakil nitelik arzettiği düşünülmeyen; bu iki olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi (suretiyle) hüküm kurulması;

2- Olayda ölen baba A'nın kızını kurtarmak için iradî olarak kuyuya atlayarak ölmesi olayında, sanığın fiili ile sonuç arasında doğrudan doğruya bir illiyet rabitası bulunup bulunmadığı karar yerinde tartışılmadan; bulunduğu kabulü halinde bu oluşa göre kusur nisbeti belirtilmeden, olayı küll halinde değerlendiren bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesi" isabetsizliğinden bozmuş(tur).

Yerel Mahkeme, "Ölenin kendi çocuğunun kuyuya düşmesi durumunda bir baba olarak onu kurtarmaktan başka bir düşüncesinin mevcut olduğunu kabule olanak yoktur. Bu düşünce içerisinde evladını kurtarmak ve ona gereken yardımda bulunmak çabası içerisinde olan ve başka herhangi bir durumu düşünecek ortamda olmayan A'nın iradî olarak kuyuya atladığını kabule, bu nedenle olanak yoktur. Sanığın mevcut fiili ile sonuç arasında bu nedenlerle doğrudan doğruya bir illiyet rabitasının mevcudiyetinin kabulü zorunlu görülmüştür" gerekçesiyle önceki hükmünde direnmiştir.

Görüldüğü gibi; Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında uyuşmazlık konusu olan husus; kuyuya düşen kızını kurtarmak için, bu kuyuya atlayan kişinin ölümünde sanığa izafe edilebilecek bir kusur, başka bir deyimle, sanığın fiiliyle ölüm olayı arasında doğrudan doğruya bir illiyet bağının mevcut olup olmadığı hususudur.

Küçük Alev'in kuyuya düşmesi ve yaralanması olayında, yaralanma olayı ile, sanığın kendisine ait kuyuya insanların düşmesini önleyecek tedbirleri gereği gibi almaması nedeniyle, illiyet bağı bulunmaktadır. Alev'in babası A. kuyuyu ve kızının bu kuyuya düştüğünü görmüş, buna rağmen kendi iradî hareketiyle kuyuya atlamış ve bu sebepten yaralanarak ölmüştür.

Bu durumda, sanığın "tedbirsizlik" olarak nitelendirilebilecek fiiliyle, A'nın ölümü olayı arasında, doğrudan doğruya bir illiyet bağının bulunduğunu kabule imkân bulunmadığından, direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.» CGK, 22.4.1985, 9-410/228 (YKD. Ekim 1985, sh: 1534 vd.)

Kanımızca karara konu teşkil eden olayda meydana gelen ölüm neticesi bakımından dikkat ve özen yükümlülüğü ihlâl edilmiştir ve sanığın taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan dolayı cezalandırılması gerekirdi.

³⁵⁰ «... Sanığın av tüfeğini dolu olarak duvara asmış olduğu, dokuz yaşındaki oğlu Sabahattin'in bunu oradan alıp kurcalarken patlayan tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığı (olayda;) sanığın fiilinin av tüfeğini küçük çocuğunun eline kolaylıkla geçmemesini sağlayacak gerekli tedbirleri almamaktan ibaret olduğu, yaralanmayı husule getiren hareketle sanığın fiili arasında bir irtibat bulunmadığı gözetilmeden;» taksirle yaralama suçundan dolayı mahkumiyet hükmü kurulmuş olması bozmayı gerektirmiştir: 4. CD, 4.5.1976, 3128/3121 (YKD. Eylül 1976, sh. 1384). Aynı mealde 2. CD, 10.5.1990, 4414/5061 (Keskin, sh. 44); 2. CD, 30.1.1990, 562/812 (Keskin, sh. 44); 2. CD, 12.9.1989, 6136/7444 (Keskin, sh. 45).

Bu hususla ilgili olarak Yargıtay'ın diğer kararları için Kitabımızın dördüncü basısının 255. sayfasındaki 354 numaralı dipnota bakılabilir.

Kişilerin malvarlığı, vücut bütünlüğü ve hatta hayatı bakımından tehlikeler içermesine rağmen belirli faaliyetlerin icrasında kişiler için yarar bulunmaktadır. Bu nedenle, tehlike oluştursalar bile, bu tehlikelerin önlenmesini sağlamak için belirlenmiş olan kurallara uygun olarak icra edilmeleri kaydıyla, bu faaliyetlere izin verilmektedir. Başka bir ifadeyle, oluşturdukları tehlikelerin önlenmesine yönelik olarak belirlenmiş kurallara uygun bir şekilde icra edilmeleri halinde, bu faaliyetlerin hukuka aykırı bir yönü bulunmamaktadır.

Örneğin karayolu trafiğine çıkmak, kişinin kendisinin veya başkalarının malvarlığı, vücut bütünlüğü ve hatta hayatı bakımından bir tehlike oluşturmaktadır. Ancak, karayolu trafiği için belirlenmiş olan kurallara uygun davranılmak kaydıyla, bu tehlikelilik durumunu büsbütün ortadan kaldırmak imkanı bulunmasa bile, kişilerin trafiğe çıkmasına hukuken cevaz verilmektedir. Karayolu trafiği için belirlenmiş olan kurallara uygun davranarak trafiğe çıkan kişinin fiili hukuka uygundur.

Trafiğe çıkan kişi, karayolu trafiği için belirlenmiş kurallara uygun davranmasına rağmen, çeşitli sebeplerle meydana gelen trafik kazası sonucunda kişilerin malvarlığına zarar verilmiş, kişiler yaralanmış ve hatta ölmüş olabilir. Karayolu trafiği için belirlenmiş olan kurallara uygun davranan kişi, kazaya karışmış olmakla birlikte, kazaya sebebiyet veren kişi değildir. Bu nedenle, karayolu trafiği için belirlenmiş olan kurallara uygun davranmakla beraber kazaya karışmış olan kişinin, bu kaza sonucunda meydana gelen yaralanma ve ölümlerden dolayı ceza hukuku sorumluluğundan söz edilemez. Trafikte kazaya karışmış olan kişinin, ceza hukuku bakımından sorumluluğundan söz edebilmemiz için, karayolu trafiği için belirlenmiş olan kurallardan en azından birini ihlal etmiş olması gerekmektedir.

Taksirli suç, **zarar suçu** olarak tanımlanabileceği gibi, **somut tehlike suçu** şeklinde de tanımlanabilir. Taksirle ölüme sebebiyet verme (TCK, m. 85) veya taksirle yaralamaya sebebiyet verme (TCK, m. 89), birinci duruma; buna karşılık, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (TCK, m. 171), radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine taksirle sebebiyet vermek (TCK, m. 172, f. 4) ve çevrenin taksirle kirletilmesi (TCK, m. 182) suçları, ikinci duruma örnek teşkil eder.

Dikkat ve özen yükümlülüğü, zararlı netice veya somut tehlike bakımından söz konusudur.

Taksirli suçlarda, objektif özen yükümlülüğüne aykırı olarak, dikkatsizlik ve özensizlikle gerçekleştirilen fiilin sebebiyet verdiği zararın veya somut tehlikenin gerçekleştiği anda suç tamamlanmış olur. Bu itibarla, taksirli suçlarda zarar, objektif özen yükümlülüğüne aykırı, dikkatsiz ve özensiz fiilin işlenmesinden çok sonra gerçekleşebilir. Örneğin jeolojik özellikleri itibarıyla belli bir bölgenin yapılaşmaya müsait olamamasına rağmen, bu bölgede yapı yapılmasına izin verilmesi veya bir yapının inşa edildiği tarih itibarıyla belirlenmiş teknik şartlara riayet edilmeksizin yapılması fiilleri, objektif özen yükümlülüğüne aykırı olmaları, dikkatsizlik ve

özensizlikle gerçekleştirilmeleri itibarıyla hukuka aykırı fiillerdir. Bu hukuka aykırı fiillerin sebebiyet verdiği zarar, çok sonra meydana gelen bir depremin tetikleme-siyle gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda, taksirli suç, objektif özen yükümlülüğüne aykırı, dikkatsiz ve özensiz fiilin işlendiği anda değil, bu fiilin sebebiyet verdiği zararın gerçekleştiği anda tamamlanmış olur. Bu durum, dava zamanaşımının işle-meye başlaması bakımından büyük önem taşımaktadır.

C. Taksirle İşlenen Fiilden Dolayı Kusurluluk

Taksirli davranışla gerçekleştirilen haksızlıklarda fail, kendi şahsi kabiliyetleri, algılama gücü, tecrübeleri, bilgi düzeyi ve içinde bulunduğu şartlar itibarıyla, objektif olarak mevcut bulunan özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmalıdır³⁵¹. Bütün bu kabiliyetlere şahsen sahip olan kişi, buna rağmen bu yükümlülüğe aykırı davranması sonucunda bir hukuki de-ğeri ihlal etmesi, bu değerini ilişkin olduğu konuyu zarara uğratması veya somut bir tehlikeye maruz bırakması durumunda, taksirli haksızlıktan dolayı kusurlu telâkki edilecektir³⁵². Bu itibarla, kişi, dikkat ve özen yükümlülüğünün mevcu-diyetini ve muhtevasını idrak edebilecek ve aynı zamanda bu doğrultuda hare-ket edebilecek durumda olmalıdır³⁵³. Dikkat ve özen yükümlülüğünün kişi tara-fından algılanabilir olması, aynı zamanda bu yükümlülüğe aykırılık dolayısıyla meydana gelen neticenin öngörülebilir olmasını da ifade etmektedir³⁵⁴.

Nitekim, maddenin dördüncü fıkrasında, bu gerçek şu şekilde ifade edilmiştir:

“Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.”

Madde gerekçesinde, taksirli suçlardan dolayı kusurlulukla ilgili olarak, ayrıca açık-lama yapmaya gerek olmayan, şu tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

«Taksirle işlenen suçlardan dolayı kusurluluk, bir değerlendirmeyeyle ancak olay hâkimi tarafından yapılabilir. Bu nedenle, taksirden dolayı kusurlulu-ğun matematiksel olarak ifadesi mümkün değildir. Ancak, normatif de-ğerlendirmeyeyle hâkim tarafından belirlenen kusurluluk göz önünde bulundu-rulmak suretiyle, suçun cezasında belli bir oranda indirim yapılabilir.

³⁵¹ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Suçun Yapısında Kusur*, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul 1997, sh. 50 vd.; ÖZGENÇ/ŞAHİN, *Uygulamalı Ceza Hukuku*, sh. 241 vd.; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, *Suç Teorisi*, 2. bası, sh. 254 vd.; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, *Genel Hükümler* (13), sh. 456 vd.

³⁵² JESCHECK, *Lehrbuch*(4), sh. 510, 536 vd.; WESSELS(19), sh. 203, 208, 216; ROXIN, *Lehrbuch*(1), 24/102 vd. Ancak, doktrinde bir görüş, objektif özen yükümlülüğünün müşahe-de edilebilir olmasını “taksirli suç”un, taksirli haksızlığın manevî unsuru olarak telâkki et-mektedir: MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 112, 138 vd.

³⁵³ JESCHECK, *Lehrbuch*(4), sh. 536 vd.

³⁵⁴ JESCHECK, *Lehrbuch*(4), sh. 539.

Taksir dolayısıyla kusurun belirlenmesi normatif bir değerlendirmeye mümkün olmakla birlikte, somut olayda dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâl edilip edilmediğinin belirlenmesi açısından bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. Örneğin ölümle sonuçlanan bir ameliyat sırasında hastaya yapılan tıbbi müdahalenin tekniğine uygun olarak yapılmış olup olmadığının belirlenmesi açısından bilirkişi incelemesine gerek bulunduğu muhakkaktır. Keza, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir trafik kazasında, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarının, hangi trafik kuralının ne suretle ihlâl edildiğinin, trafiğe çıkarılan aracın teknik bakımdan herhangi bir arızasının olup olmadığının belirlenmesi açısından da bilirkişi incelemesi yapılabilir. Ancak, bu durumlarda, bilirkişinin yapacağı inceleme, işin tekniği ile sınırlı olmalıdır. Bunun dışında, bilirkişi tarafından münhasıran hâkimin yetkisinde bulunan kusurluluk konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamalıdır. Aksi yöndeki tutum, bilirkişilik görevinin sınırını aşmayı ve hâkimin yerine geçmeyi ifade eder.

Hâkim, bu teknik veriler çerçevesinde somut olayda failin kusurlu olup olmadığını takdir edecektir. Failin kusurlu bulunması durumunda, kusurun ağırlığı ve diğer sebepleri de göz önünde bulundurmak suretiyle suçun kamu ni tanımındaki cezanın alt ve üst sınırı arasında bir cezaya hükmedecektir.»

D. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; TCK'daki iştirake ilişkin hükümleri taksirli suçlar açısından uygulamak hukuken mümkün değildir (m. 40)³⁵⁵. Ancak, somut olayda failin gerçekleştirdiği taksirli davranışa bir başkasının taksirli davranışı eklenmiş olabilir.

Birden fazla kişinin dikkatsiz ve özensiz davranışı sonucunda taksirle sebebiyet verilen ölüm veya yaralanmalardan dolayı sorumluluk için bu kişiler arasında “asli” kusurlu – “tali” kusurlu ayırımı yapılmasının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Keza, mülga 765 sayılı TCK'nın düzenlemeleri itibarıyla uygulamamızda kabul görmüş olan taksirli suçlarda kusurluluk bağlamındaki 8/8 ilâ 1/8 üzerinden değerlendirmenin yeni TCK'nın sisteminde bir dayanağı kalmamıştır.

Birden fazla kişinin sebebiyet verdiği haksız fiil nedeniyle özel hukuk alanında ki tazminat sorumluluğu müsterek ve müteselsil sorumluluk olduğu için, haksız fiilin oluşumuna sebebiyet veren kişilerin sorumlulukları bağlamında kusurlarını belirli yüzdeler olarak belirlemek ve bu oranlar toplamını 100'e iblağ etmek mümkün ve hatta gereklidir. Her ne kadar birden fazla kişi, sebebiyet verdikleri haksız fiil nedeniyle bu fiile maruz kalana karşı özel hukuk alanında müteselsilen sorumlu iseler de, bu sorumluluğun kendi aralarındaki paylaşımı bakımın-

³⁵⁵ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 142, 292/293, 316.

dan, kusurlarının belirli yüzdeler olarak belirlenmesi ve bu oranlar toplamının 100'e iblağ edilmesi önem taşımaktadır.

Buna karşılık, birden fazla kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı sonucunda sebebiyet verilen ölüm veya yaralanmalardan dolayı bu kişilerin ceza hukuku sorumluluğu bağlamında kusurlarının oransal rakamlarla ifade edilmesine gerek bulunmamaktadır. Hatta böyle bir yöntem, yanlış anlaşılmalara ve uygulamalara sebebiyet vermektedir. Şöyle ki, mülga 765 sayılı TCK uygulamasında, taksirle sebebiyet verilen bir ölümden dolayı sorumluluk belirlenmesinde, kişilerin yanı sıra, yolun ve hatta yola çıkan hayvanın da kusurlu bulunması gibi örneklerle karşılaşmıştır. Keza bu uygulamada, kusurlu bulunan kişiler ve kusur teşkil eden faktörler arasında toplamı 8/8'e iblağ edilecek şekilde bir kusur dağılımının yapıldığı gözlemlenmiştir³⁵⁶.

³⁵⁶ Bu tür değerlendirmelere yeni TCK yürürlüğe girdikten sonra verilen mahkeme kararlarında da rastlanmaktadır:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4.7.2017 tarihli ve E. 2016/12-1418, K. 2017/362 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Seyhun, sevk ve idaresindeki otomobille 27.08.2012 günü saat 16.30 sıralarında, meskun mahal dışında, orta refüjle bölünmüş yolda seyrederken, yola iki at çıkar. Seyhun, bu atlara çarpmamaya çalışırken, aracın kontrolünü kaybeder. Araç, orta refüje çıkar, oradan da karşı istikametten gelen araçların seyrettiği yola geçer ve Bekir'in sevk ve idaresindeki kamyonete çarpar. Kazada, Seyhun'un yönettiği otomobilde bulunan eşi Özge ölür, kızı Defne yaralanır. Kamyonetin sürücüsü Bekir ile kamyonette bulunan diğer iki kişiden Ayşegül ölür ve Hatice yaralanır.

Bu olayla ilgili olarak Terme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, eşi Özge'nin ölümü ve kızı Defne'nin yaralanması bağlamında şahsi cezasızlık sebebinin varlığı kabul edilerek, Hatice'nin ise şikâyetçi olmaması nedeniyle Seyhun hakkında kovuşturmayaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Buna karşılık, Bekir ile Ayşegül'ün ölümü sebebiyle, Seyhun hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan dolayı iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.

Bu olayda, Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi, Seyhun hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan dolayı TCK, m. 85, f. 2; 62 ... hükümleri gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezasına ve 3 yıl süre ile sürücü belgesinin geri alınmasına hükmetmiştir (30.10.2013, 15-194).

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bu hükmün onanmasına karar vermiştir (24.03.2015, 10866-5011).

Seyhun hakkında hükmolunan hapis cezası adli para cezasına çevrilmemiştir. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 12. Ceza Dairesinin onama kararına itiraz etmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, ilk derece mahkemesinin hapis cezasının adli para cezasına çevrilmemesi yönündeki takdirinde herhangi bir hukuka aykırılık görmemiştir.

Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda;

*“yola aniden iki atın girmesi sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı yöne girdiği anlaşılan **sanığın**, yeterli dikkat ve özeni göstermeyerek atlar nedeniyle aracı kaplamada tutacak şekilde tedbir almadığından **%60 oranında** asli derecede **kusurlu** olduğu, yola giren **atların** kazanın oluşumunda **%40 oranında** tali derecede etkili olduğu, diğer araç sürücülerinin ise kusurunun bulunmadığı,”*

değerlendirmesine yer verilmiştir.

Bu olayda, Seyhun'un hangi trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız kuralına riayet edip etmediği, trafik kazası tespit tutanağında ve bilirkişi raporlarında açık bir şekilde tespit edilme-

Meselâ, trafiğe açık ve işlek anayol üzerinde bulunan binanın yıktırılması işini üzerine alan müteahhit, yıkma işine başlarken, yoldan geçenlerin zarara uğramaları ihtimaline karşı binanın yol üzerindeki cephesine tahta perde kurması gerekirken bunu yapmaz. Ayrıca, yıkma işinde çalışanlardan iki işçi de yolda kimsenin bulunup bulunmadığına dikkat etmeksizin binadan sökülen büyük bir kalası sokağa atarlar. Neticede yoldan geçen bir kişi ölür veya yaralanır³⁵⁷. Failin taksirli hareketinin bir başkasının taksirli hareketiyle birleşmesi halinde, **herkes kendi taksirli fiilinden dolayı, kusuruna göre sorumlu tutulacaktır.** Ancak, belirtmemiz gerekir ki; bu gibi durumlarda önceki taksirli hareketle ne-

miştir. Olayda yola çıktığı belirtilen atlara çarpmamak için Seyhun'un araç frenine basıp basmadığı, olay mahallinde fren izi olup olmadığı, atların yola çıktığı nokta ile yola çıktıkları an itibarıyla Seyhun'un aracının bulunduğu nokta arasındaki mesafenin ne olduğu tespit edilmemiştir.

Bütün bu bilgiler, Seyhun'un bölünmüş yoldaki hız sınırına ilişkin kurallara riayet edip etmediğinin tespitinde göz önünde bulundurulacaklardır. Bu eksikliklere rağmen, **kusurluluk ile ilgili olarak hiçbir bilimsel dayanağı olmadan oransal belirlemelere** gidilmiştir. Bu belirlemelerde, **Atlara** da **"KUSUR"** izafesinde bulunulmuştur.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarında dava dosyasındaki bu eksikliğin giderilmesine yönelik bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Ceza Genel Kurulu Kararında sadece Seyhun hakkında hükmolunan 4 yıl 2 ay hapis cezasının adli para cezasına çevrilip çevrilmemesi bağlamında bir değerlendirme yapılmıştır.

Karara konu teşkil eden olayda, taksirle ölüme veya yaralamaya sebebiyet verme suçunda, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarında olduğu gibi, ölen ve yaralanan kişi sayısının suç olduğu izlenimi uyandıran bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Esasında olayda TCK, m. 85 kapsamında değerlendirilen **bir taksirli suç** mevcuttur. Ancak bu taksirli suçta birden fazla kişi ölmüş ve birden fazla kişi yaralanmıştır. Bu durumda, TCK, m. 43, f. 3 hükmünde olduğu gibi, birden fazla taksirli suçun varlığı kabul edilemez. Bu durumda bir taksirli suçun varlığının kabulüne rağmen, TCK, m. 85, f. 2'de ceza miktarına ve cezanın belirlenmesine ilişkin özel hükme yer verilmiştir.

Bu itibarla Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Seyhan'ın taksirle sebebiyet verdiği trafik kazasında ölen veya yaralanan kişilerden bir kısmıyla ilgili olarak hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi doğru olmamıştır.

Aynı değerlendirme trafik kazasında yaralanan kişilerin şikayeti bakımından da geçerlidir. Yani söz konusu trafik kazasında ölenlerin yanı sıra yaralananların da bulunması, suç sayısının çokluğuna işaret etmemektedir. **Suç tektir.** Ancak bu suçun işlenmesi bağlamında yaralanan kişiler şikayet hakkından vazgeçmiş veya şikayetini geri almış olabilir. Karara konu teşkil eden trafik kazasında, iki kişinin ölmüş olması dolayısıyla, söz konusu taksirli suç sebebiyle bir iddianame düzenlenmesi ve yaralanan kişilerden birinin şikayetten vazgeçmiş olduğunun iddianamede belirtilmesiyle yetinilmeliydi. Başka bir ifadeyle, trafik kazasında aile bireyleri dışında başka kişiler de ölmüş olduğu için, ölen veya yaralananlardan bir kısmının kazaya sebebiyet veren sürücünün ailesi bireylerinden olması bağlamında şahsi cezasızlık sebebinin varlığından bahisle fail hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmemesi gerekirdi. Keza, sebebiyet verilen trafik kazasında birden fazla kişi ölmüş olduğu için, yaralanan kişilerden birinin şikayetten vazgeçmesi, bu kişi ile ilgili olarak da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmemeliydi. Bütün bu hususların, söz konusu taksirli suç sebebiyle açılan kamu davasında mahkemenin TCK, m. 85, f. 2 hükmüne istinaden temel cezanın belirlenmesi bağlamında dikkate alınması gerekirdi.

³⁵⁷ Örnek, İÇEL, Taksir, sh. 175'ten alınmıştır.

tice arasındaki illiyet bağının bulunmamasından³⁵⁸ veya kesilmiş olmasından³⁵⁹ söz edilmesi doğru değildir.³⁶⁰

³⁵⁸ «Kamyon şoförü olan sanık Y.E.nin, otomobil kullanmada tecrübesi bulunduğunu ve ehliyet almak için çalışmakta olduğunu bildiği köylüsü ve arkadaşı R.Ş.nin “kamyonu biraz da ben kullanayım” diye rica etmesi üzerine kamyonun yönetimin kendisine bıraktığı; kamyonun yönetimi devralan R.Ş.nin, köy yolunda otomobili yönetirken direksiyona hakim olamayarak kamyonun şarampole (yuvarlanmasına) sebebiyet vermesi sonucu kendisi ile kamyonunda bulunan iki çocuğun ve arkadaşı A.K.nin ölümüne, kızı A.Ş.nin de yaralanmasına sebebiyet vermesi üzerine; kamyonunu R.Ş.ye veren sanık hakkında, “ehliyetnamesiz şahsa otomobilinin yönetimin bırakmak” suretiyle tedbirsizlikle ölüme sebebiyet vermek suçundan dolayı kamu davası açıldığı anlaşılmıştır. Üçüncü şahsın aslı faille birleşik kusuru sonuçla bir illiyet bağının bulunması halinde kabul edilmiştir.

Hal böyle olunca ölüme neden olan ehliyetsiz R.Ş.nin fiili ile kamyonun yönetimini kendisine veren şoför sanık Y.E.nin fiili arasında bir *illiyet bağının bulunmadığı* kabulü gerekmektedir. Zira, kamyonu kullanan ve ölüme sebebiyet veren ve bu itibarla da aslı fail durumunda bulunan R.Ş., kamyonun yönetimini şoför Y.E.den almış ve direksiyona geçip yönetirken virajı alırken kamyonu devirmek suretiyle, kendi taksirli hareketleri sonucu olarak ölüme sebebiyet vermiştir.

Bu biçimde oluşan olayda üçüncü şahıs durumunda bulunan sanığın birleşik kusurundan söz edilemez ve tecziyesi cihetine de gidilemez.»: CGK, 21.2.1983, 9-561/68 (Keskin, sh. 31 vd.).

«Olay günü avdan dönen sanığın, av arkadaşı ölen Y.nin verdiği sigarayı yakabilmek için, elindeki dolu ve tetiği kalkık bulunan tekli kırma av tüfeğini hükümlü A.ya verdiği ve A.nin da eline alınca, tetiğini çekmek suretiyle, tüfeğin ateş alması sonunda; yaralanan Y.nin öldüğü ve böylece ölümü tevhit eden ateş almayı doğuran fiilin, tüfeği veren sanık D. tarafından değil, tetiği çeken A. tarafından işlendiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, D.nin kusurlu hareketi ile sonuç arasında doğrudan doğruya *illiyet rabtası bulunma*»maktadır: CGK, 13.5.1974, 8-131/282 (Keskin, sh. 44).

³⁵⁹ “Ancak failin taksirli harekette bulunarak bir kimseyi öldürmesine bu kişinin veya üçüncü bir şahsın taksirli hareketi sebep olduğu takdirdedir ki, failin taksirli hareketiyle netice arasında *illiyet bağı kesilmiş* olur.” (ERMAN, Erman/Özek, Kişilere Karşı Suçlar, sh. 84). “Failin taksirli harekette bulunması, bir başkasının daha önce taksirli bir harekette bulunmasından ileri gelmişse, *failin hareketiyle netice arasında illiyet bağı bulunmaz* ve bu bağ failin taksirli hareket etmesine yol açan hareketle ölüm neticesi arasında kurulur.” (aynı eser, sh. 85).

³⁶⁰ Nitekim, Yargıtay, benzer olaylarla ilgili kararlarında objektif özen yükümlülüğüne aykırı davranış ile meydana gelen netice arasında illiyet bağlantısının varlığını kabul etmektedir. Bu kararlarda tartışma konusu edilen husus, sübjektif isnadiyeti ifade eden sorumluluğun izahıdır:

«Olay, motosikletli sanık N.nin diğer sanık yaya M.ye çarpması sonucu meydana geldiği cihetle, hadisenin oluşuna ve her iki yaralanmaya motosikletle çarpmanın sebep olduğu; ancak yaya M.nin bu olayın meydana gelmesinde yol üzerindeki konumu itibarıyla müterafik kusurunun bulunduğu; bu halin sanık N.nin kusur oranına etkili olacağı ve *mücerret mağdura kusur izafesinin onu sanık durumuna sokmayacağı* nazara alınarak sanık M. hakkında beraat kararı ittihazi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü tesisi bozmayı gerektirmiştir.».

«Olayda 3/8 nisbetinde kusurlu görülen bu nedenle mahkûm olan A.M.G. kullandığı oto ile, yolda normal olarak park etmiş olan kamyonun yanından geçmekte iken bu kamyonun önünden sanığın karşı tarafa geçmek için aniden fırladığı; A.M.G.nin de anı fırlayan bu şahsa çarpmamak için direksiyonu sola kırdığı, bu nedenle oradan bisikletle geçmekte olan B.B.ye çarptığı ve ölümüne sebep olduğu anlaşılmaktadır.

Ölüm, A.M.G.nin kullandığı otomobilin çarpması ile meydana gelmiş ise de *yaya geçen sanığın fiili ile (ölüm neticesi) arasında doğrudan bağlantı ve illiyet sebebi vardır*. Otomobil kullanan A.M.G aniden önüne fırlayan sanığa çarpmamak ve onu ezmek için direksiyonu sola kırmış ve bisikletli şahsa çarpmıştır. Başka bir deyimle, direksiyonun sola kırılması ve bisik-

Failin gerçekleştirdiği taksirli harekete mağdurun hareketi eklenmiş olabilir. Meselâ, fail otomobiliyle azamî sür'at sınırını aşarak seyretmektedir. Ancak, bu sırada gerekli dikkat ve özeni göstermeden karşı kaldırıma geçmek isteyen ya-
yaya çarparak ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet verir. Bir şoför gece vakti
arıza yapan kamyonunu yeterince yolun kenarına çekmediği gibi, lambalarını
yakmak veya herhangi bir işaret koymak suretiyle diğer sürücülerini uyarmaz.
Otomobiliyle azamî hız sınırının üzerinde seyreden kişi bu kamyonu çarparak
ölür veya yaralanır. Bu gibi olaylarda gerek failin gerek mağdurun taksirle ha-
reket ettiklerini kabul etmek gerekir; çünkü, her ikisi de trafikle ilgili kurallara
riayet etmemişlerdir. Mağdur taksirle hareket etmiş olsa bile, fail, kendi taksirli
hareketi dolayısıyla kusuruna göre sorumlu tutulacaktır³⁶¹. Ancak, belirtmek
gerekir ki; taksirler arasında takas cereyan etmez³⁶².

letli şahsa otomobilin çarpması sanığın fiilinin bir sonucudur. Sanığın tedbirsizlik ve dikkat-
sizliği sabittir. TCK'nın 455. maddesine uyan fiillerde kusur nisbetinde ceza verilmesi prensi-
bi kabul edilmiştir. Kusurlu olan kimsenin ölmesi bu kuralı değiştirmemelidir. Otomobili kul-
lanan şahsın fiiline etkili olduğuna göre olayda doğrudan illiyet rabitası da vardır.»: 9. CD,
5.12.1977, 2429/3973 (Keskin, sh. 29).

Ayrıca bkz. CGK., 28.12.1970, 4-361/432 (Keskin, sh. 34, 84).

³⁶¹ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20.05.2008 tarihli ve E. 2008/9-51, K. 2008/117 sayılı Ka-
rarına konu teşkil eden olayda:

M'nin yönetimindeki, TIR çekici ve arkasında yer alan kömür yüklü yarı römork şeklindeki
TIR ile Z'nin yönetimindeki otomobil, gece saat 00.15 sularında yerleşim yeri dışında çarpı-
şır. Z, olay yerinde ölür. Çarpışma, “yandan çarpma” şeklinde cereyan eder. Otomobil, TIR
çekicisine sol ön teker hizasından çarpar. Kaza sırasında hava açık, yol yüzeyi kurudur. 5.60
metre genişliğindeki asfalt kaplama yolda yol şerit çizgisi yoktur. Kaza noktasında Z'nin gidiş
yönüne göre yolun her iki tarafında sağa viraj levhası mevcuttur. Çarpışma noktası, hemen vi-
raj çıkışında Z'nin gidiş yönüne göre sağdan 3,60 metre, M'nin gidiş yönünde ise sağdan 2,00
metre mesafededir. Yani Z, kontrolündeki otomobille, sağ tarafta yeterli mesafe bulunmasına
rağmen, sola kayarak viraja girer. Olay yerinde, otomobile ait fren izi yoktur; TIR çekicisine
ait ise, çarpışma noktasından başlayıp yol dışında sonlanan sağ tekerlek için 35 metre, sol te-
kerlek için ise 32 metre fren izi mevcuttur. M, kaza sırasında alkollüdür. Saat 01,08 itibarıyla
yapılan ölçüme göre promil değeri 0,23'tür. Kazanın meydana geldiği yol, TIR araçlarının
girmesine yasak yoldur ve yol girişinde yasak levhası mevcuttur. TIR çekicisinde bulunan ta-
kograf cihazı olay sırasında çalışır durumda değildir.

M hakkında taksirle ölümüne sebebiyet verme suçundan dolayı açılan davada Esas Mahkemesi,
trafik kazasının tamamen Z'nin kusuruyla meydana geldiği ve Z'nin ölümü bakımından
M'nin kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle, M'nin beraatine hükmetmiştir.

Yargıtay 9. CD, temyiz incelemesi sonucunda M'nin TIR araçlarının girmesi yasaklanmış olan
yola girmesi ve kaza sırasında alkollü olması dolayısıyla, “*içinde bulunduğu şartlar itibarıyla trafik
kurallarına aykırı hareket ederek gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamak suretiyle netice-
nin meydana gelmesinde kusuru bulunduğu*” gerekçesiyle, bu beraat kararını bozmuştur.

Esas Mahkemesi, trafik kazasının M'nin alkollü olması ve kullandığı araç bakımından yasak-
lanmış yolda seyretmesi sebebiyle meydana gelmediği, M'nin trafik kurallarına aykırı olan bu
davranışları ile meydana gelen ölüm neticesi arasında illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle,
önceki kararında direnmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıda özetlemiş olduğumuz ve bizim de katıldığımız gerekçe
ile, Esas Mahkemesinin direnme kararının bozulmasına karar vermiştir:

“Z’nin kendi ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının meydana gelmesi bakımından kusurunun bulunduğu hususunda kuşku yoktur. Z, otomobiliyle seyrederken trafik düzeninin gerekli kaldığı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş ve pek çok trafik kuralını ihlal etmiştir. Z, yeterli mesafe bulunmasına rağmen yolun sağını takiben seyretmemiş ve viraj nedeniyle görüş mesafesinin daralmasına rağmen, sola kayarak karşı istikametten gelen araçların yoluna girmiştir. Kullandığı otomobile ait olay yerinde fren izinin bulunmaması, Z’nin aracı azami hız sınırının üzerinde bir hızla sürdüğünü ve bu nedenle karşı yönden gelen aracı fark edemediğini göstermektedir.

Olay yerinde, çarpışma noktasından önce TIR aracına ait fren izi mevcut değildir. M, TIR aracının frenine çarpışmadan sonra basmış ve araç, çarpma noktasından 35 metre ileride devrilerle durabilmiştir. Bu durum da, M’nin aracı azami hız sınırının üzerinde bir hızla sürdüğünü göstermektedir. Her ne kadar TIR aracı ile olay sırasında yolun sağ tarafında seyretmekte ise de, TIR araçlarının girişinin yasak olduğu bu yola girmiş olması trafiğin emniyetli akışına engel teşkil ettiğinden, M’nin meydana gelen netice bakımından taksirinin varlığını kabul etmek gerekmektedir.”

Ancak, Yargıtay’ın bu bağlamda eleştiriyi hak eden kararları da mevcuttur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 16.10.2007 tarihli ve E. 2007/9-192, K. 2007/211 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda:

25.08.1984 doğumlu olan lise öğrencisi S, 14.04.2002 tarihinde arkadaşları ile birlikte oynamak üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi açık spor tesisleri içindeki basketbol sahasına gider. S, basketbol sahasındaki arızalı basket potasına koşarak asılır. Bu nedenle kırılan basket potası S’nin üzerine düşer ve ölümüne sebebiyet verir.

Hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dolayı açılan davada Esas Mahkemesi, basket potasının tamir işini üstlenen yükleniciyi mahkum etmiştir.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, meydana gelen ölüm neticesinin tamamen ölenin kusurundan meydana geldiği gerekçesi ile bu kararı bozmuştur. Esas Mahkemesi kararında direnmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıda özetlediğimiz gerekçe ile, Esas Mahkemesinin direnme hükmünün bozulmasına karar vermiştir:

Üzerine düşerek S’nin ölümüne sebep olan pota, zemine bağlantı kısmından öne doğru kısmen eğiktir, zemine bağlantı yerindeki asfalt kazılmıştır ve fakat demir bir boruyla desteklenmiştir.

Sanık, üstlendiği taahhüt işleri kapsamında *“eğik durumda bulunan basket potasının tamiri işini de”* üstlenmiştir. Böylece potanın eğik olması dolayısıyla *“gerekli önlemlerin alınması sorumluluğu üniversite yönetiminden sanığa geçmiştir. İşin sözleşme haricinde hatıra ya da üniversite yönetimi ile olan iyi ilişkilere binaen üstlenilmiş olması, sanığın tamir süresince gerekli önlemleri alma sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Ancak bu husus, meydana gelecek bütün sonuçların sorumluluğunun ceza hukuku ilkelerine aykırı olarak nedensellik bağı aranmadan doğrudan sanığa ait olacağı anlamına da gelmemektedir.”*

Sahanın etrafı tel örgü ile çevrili olmasına rağmen, kapısız iki girişi bulunmaktadır ve kişilerin kontrolsüz bir şekilde dışarıdan sahaya gelerek oyun oynamaları mümkündür. Davada her iki girişte okunur bir şekilde *“tadilat dolayısıyla basket sahasına girmek yasaktır”* uyarı yazısı bulunduğu hususundaki savunmanın gerçekte bağdaşıp bağdaşmadığı tespit edilememiştir. Ancak *“olayın meydana geldiği yer ve çevresinde olaydan önce herhangi bir uyarı yazısının (bulunmamasının, somut olaydaki ceza sorumluluğu bakımından) bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığı kabul edilse bile birden fazla sağlam potanın bulunduğu bir sahada yerle bağlantı noktasındaki asfalt kazılmış ve altından demir bir boruyla desteklenmiş olan eğik durumdaki bir potanın bu mevcut tehlikeli görünüşünün asılabilecek bütün uyarı yazıları ve işaretlerinden daha uyarıcı olduğu açıktır.”*

Ölen lise öğrencisinin, *“olay tarihinde davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olduğuna ilişkin de kuşku bulunma”* maktadır ve *“arkadaşlarıyla geldiği basketbol sahasında oynayabileceği başka sağlam potalar varken, olağan dışı bir şekilde eğik duran ve yerle bağlantı nok-*

Yeni TCK'nın 22. maddesinin beşinci fıkrasına bu konu ile ilgili olarak şu hüküm konmuştur:

“Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.”

Madde gerekçesinde, bu hususla ilgili olarak, ayrıca açıklama yapmaya gerek olmayan, şu tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

«Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiyle sorumlu tutulur. Taksirli suçun kanuni tanımında belirlenen netice birden fazla kişinin karşılıklı olarak işledikleri taksirli fiiller sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Örneğin bir trafik kazasında sürücü ile yaya veya her iki sürücü de taksirle hareket etmiş olabilir. Bu gibi durumlarda neticenin oluşumu açısından her kişinin taksirli fiili dolayısıyla kusurluluğu bir diğerinden bağımsız olarak belirlenmelidir.

Aynı şekilde birden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ameliyatın ölüm veya sakatlıkla sonuçlanması durumunda, ameliyata katılan kişiler müştereken hareket etmektedirler. Ancak tıbbın gereklerine aykırılık dolayısıyla ölüm veya sakatlıkla sonuçlanan bu ameliyatta işlenen taksirli suçun işlenişi açısından suçta iştirak kuralları uygulanamaz. Kanunun su-

tasındaki asfalt kazılarak kullanılamayacak bir görüntüye kavuşturulan, bununla da yetinil-meyerek demir bir boruyla desteklenen ve devrilmeye elverişli bu durumu itibarıyla da asıl-manın tehlikeliliğini her gözleyene açıkça gösteren potanın çemberine koşarak gelip asıldığı ve tümüyle kendi kusurlu hareketi sonucu potanın kendi üzerine düşmesine sebebiyet verdiği sabittir. Bu tür bir oluştaki başkalarının müterafık kusurunun varlığını ve etkinliğini aramak ve ceza sorumluluğunu bu dağılımla belirlemek isabetli değildir. Ölenin bizatihi kendi kusurlu eylemiyle gerçekleşen bu olaydan dolayı sanığın cezaen sorumlu kabul etmek olanaksızdır.”

Yargıtay'ın kararının tutarsız yönü, meydana gelen netice ile failin icrai veya ihmali davranışı arasındaki illiyet bağının varlığının, sorumluluk türüne göre belirlenmesidir. Yüklenici konumundaki sanık tamir işini üstlenmekle bu tamir faaliyeti dolayısıyla kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü ve malvarlığı itibarıyla zarar görmemeleri için gerekli tedbirleri almak yükümlülüğü altına girmektedir. Bu itibarla, yüklenicinin gerekli tedbirleri almaması dolayısıyla tamir faaliyeti sırasında kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı itibarıyla uğradıkları zararlar bakımından tazminat sorumluluğunun olabileceği kabul edilmektedir. Ancak Yargıtay, ceza sorumluluğu bakımından gerçekleşen ölüm neticesiyle, sanığın dikkatsiz ve özensiz fiili arasında nedensellik bağının bulunmadığı yargısına ulaşmaktadır.

Somut olayda lise öğrencisi olan ölenin, dikkatsiz ve özensiz davranışının olduğu kuşkusuzdur. Ancak, ilginç olan, ölenin “basketbol sahasında oynayabileceği başka sağlam potalar varken,” oynamak için bu arızalı basket potasını seçmiş olmasının, yüklenicinin bu ölüm neticesinden dolayı ceza sorumluluğunun olmadığı yönündeki kararın gerekçesi yapılmış olmasıdır.

Karar içeriğinde, Üniversite yönetiminin veya yüklenicinin basketbol sahasındaki çürük ve arızalı basket potasından dolayı kişilerin zarar görmemesi için potayı demir bir boru ile desteklemek dışında başka bir tedbir aldıklarına dair bilgi bulunmamaktadır.

³⁶² DÖNMEZER/ERMAN II, no. 978; İÇEL, Taksir, sh. 179 vd.

ça iştirake ilişkin hükümleri, kasten işlenen suçlarda suçun işlenişine iştirak eden kişilerin sorumluluk statülerini belirlemektedir. Birden fazla kişinin katılımıyla yapılan ameliyat sırasında meydana gelen ölüm veya sakatlık neticeleri bakımından her bir kişinin sorumluluğu kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmelidir. Bu tespit diğer kişilerin kusurlu olup olmadığı hususu dikkate alınmaz.»

E. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Kişisel ve Ailevi Durumu İtibarıyla Mağdur Olması

Dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâli suretiyle kişi kendisinin yaralanmasına veya aile bireylerinden birinin ölümüne ya da yaralanmasına sebebiyet vermiş olabilir. Dikkatsiz ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak araç kullanmak suretiyle bir trafik kazasına ve bu kazada kendisinin yaralanmasına ve eşinin ölümüne sebebiyet veren kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek suçundan dolayı cezalandırılması, kendisi ve ailesinin diğer fertleri bakımından ikinci bir yıkım etkisi doğurabilir. Bu gibi durumlarda somut olayın şartlarına göre taksirli davranışta bulunan kişiye ceza verilip verilmemesi, verilecekse cezasında indirim yapıp yapılmaması hususunda hakime takdir yetkisi tanınmalıdır³⁶³.

Bu düşüncelerle yeni TCK'ya bu hususa münhasır bir hüküm konmuştur:

“Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarısından altıda bire kadar indirilebilir.”³⁶⁴

Madde gerekçesinde, bu fıkra metni ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunulmuştur:

“Ülkemizde özellikle kırsal bölgelerde rastlandığı üzere, taksirli suçlarda failin meydana gelen netice itibarıyla bizzat kendisinin ve ailesi bireylerinin ağır derecede mağduriyete uğradıkları görülmektedir. Söz gelimi, köylü kadınların gündelik uğraşları ve hayat zorlukları itibarıyla, sayısı çok kere üç dörtten fazlasına varan küçük çocuklarına gerekli dikkati ve itina gösterememeleri sonucu, çocukların yaralandıkları veya öldükleri görülmektedir. Aynı şekilde meydana gelen trafik kazalarında da benzer olaylara rastlanmaktadır. Bu gibi hâllerde ananın taksirli suçtan dolayı kovuşturmaya uğraması ve cezaya mahkûm edilmesi, esasen suçtan dolayı evladını kaybetmesi sonucu uğradığı ızdırabı şiddetlendirmekle kalmamakta, ayrıca, ailenin tümüyle ağır derecede mağduriyete düşmesine neden olmaktadır.

³⁶³ ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku(2), sh. 66.

³⁶⁴ Hafizoğulları, istihzai bir üslupla söz konusu hükmü Türk kanun koyucusunun bir “icadı” olarak telakki etmektedir (HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 251 vd.).

Söz konusu fıkraya göre, hâkim suçlunun durumunu takdir ile ceza ver-meyebilecektir. Elbette ki hâkim bu husustaki takdirini kullanırken suçlu-nun ekonomik durumunu, aile yükümlerini, söz gelimi diğer çocukların bakımını göz önünde bulunduracak, ona göre hüküm kuracaktır. Ancak, dikkat edilmelidir ki, bu fıkranın uygulanabilmesi için fiilden dolayı mün-hasıran failin kişisel ve ailevî durumu itibarıyla zararlı netice meydana gelmiş bulunmalıdır; böyle bir netice ile birlikte söz konusu durumlara ilişkin bulunmayan başka bir netice de meydana gelmişse fıkra uygulan-mayacaktır. Fıkroda, yazılı suç bilinçli taksir hâlinde işlenirse ceza yarı-dan üçte birine kadar indirilebilir.”³⁶⁵

Dikkat edilmelidir ki, bu hükümle, taksirli suçlarda bir şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren bir şahsi sebep ihdas edilmiştir³⁶⁶.

Bu şahsi cezasızlık sebebinin veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebebin varlığından söz edebilmek için, “taksirli hareket sonucu neden olunan netice(nin), münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu bakımından, artık bir ce-zanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açması” gerekir. Doktrinde bu hükmün uygulanabileceği hallerle bağlantılı olarak faille mağdur arasındaki akrabalık ve sair ilişkiye dayalı tartışma yapılmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, fıkra metninde “münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu baki-mından” mağduriyetinden söz edilmiştir. Bu itibarla, söz konusu hükmün uygula-nabilmesi için sadece faille mağdur arasındaki akrabalık gibi ilişki göz önünde bulundurulamaz. Taksirle işlenen suçun failin kişisel ve ailevi durumu bakımın-dan mağduriyetini sonuçlaması gerekmektedir³⁶⁷. Kişi örneğin dikkatsiz ve özen-siz araç kullanmak suretiyle trafik kazasına ve bu kazada eşinin veya çocuklarının ölümüne sebebiyet vermişse, altıncı fıkra hükmüne istinaden cezalandırılmaya-caktır. Dikkat edilmelidir ki, bu şahsi cezasızlık sebebinin uygulanabilmesi için failin ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet verdiği kişinin örneğin eşi olması yeterli değildir. Kişi, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşinin ölümüne se-bebiyet vermesi halinde, meydana gelen sonuçtan acı ve elem değil, gizli bir memnuniyet hissetmiş olabilir. Bu durumda, failin şahsi cezasızlık sebebinden yararlandırılmayacağı muhakkaktır. Bu nedenle, söz konusu şahsi cezasızlık se-bebinin uygulanabilmesi için, sadece akrabalık ilişkisi göz önünde bulundurula-

³⁶⁵ Bilinçli taksir halinde cezada yapılabilecek indirim oranına ilişkin olarak madde metni ile madde gerekçesi arasındaki bu farklılığın sebebi, TBMM Adalet Alt Komisyonunda kabul edilen metinde, bilahare TBMM Adalet Komisyonunda değişiklik yapılmış olmasıdır.

³⁶⁶ *Meraklı*, söz konusu düzenleme ile taksirli suçlar bakımından bir şahsi cezasızlık sebebi değil, “cezaı kaldıran veya azaltan şahsi sebep” ihdas edildiği fikrindedir (MERAKLI, Ceza Huku-kunda Kusur, sh. 352 vd.). Buna rağmen, ileri sürülen bu görüş uygulama bakımından farklı bir sonuç doğurmamaktadır.

³⁶⁷ Bkz. ÖZANLI, Aytekin: *Failin Ailevi ve Kişisel Durumunun Taksirli Suçlar Bakımından Değerlendirilmesi*, in: Terazi Aylık Hukuk Dergisi, yıl 4, sayı 32, Nisan 2009, sh. 57 vd.

maz. Bu ilişkinin yanı sıra, meydana gelen neticenin failin kişisel ve ailevi durumu itibarıyla mağduriyetine sebebiyet vermesi gerekmektedir³⁶⁸. Failin acı ve elemine sebebiyet vermeyen bir netice dolayısıyla şahsi cezasızlık sebebinden yararlandırılması düşünülemez. Keza işaret etmek gerekir ki, bu acı ve elem, suç işlendikten sonra ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, duyduğu acı ve elem failin kusurluluğu üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir.

Söz konusu fıkra hükmünün uygulanabilmesi için, suçun sadece taksirle ölüme veya yaralamaya sebebiyet verme suçu (TCK, m. 85, 89) olması gerekmektedir. Örneğin “*Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması*” suçu da (TCK, m. 171) bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bu itibarla, örneğin dikkatsiz ve özensiz davranışlarıyla kendi evinin yanıp kül olmasına ve çoluk çocuğunun evsiz barksız kalmasına sebebiyet veren kişi, altıncı fıkra düzenleneni şahsi cezasızlık sebebinden yararlandırılacaktır.

Kanaatimizce, bu fıkra hükmünde, şahsi sebebin ortaya çıkması halinde faile ceza verip vermemek, verecekse cezasında indirim yapıp yapmamak hususlarında hakime takdir yetkisi tanınması daha yerinde olurdu³⁶⁹. Yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısında (m. 21, f. 4) olduğu şekliyle kanunlaşan bu hükmün TBMM Adalet Alt Komisyonundaki müzakereleri sırasında düşüncemiz doğrultusunda değiştirilmesi girişimimiz sonuçsuz kalmıştır.

Söz konusu fıkra hükmünün formülasyonunda bir başka sorun daha bulunmaktadır: Şahsi cezasızlık sebebinden yararlanabilmesi için, taksirle işlediği suçun “*münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açması*” gerekmektedir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak araç kullanmak suretiyle bir başkasının ölümüne sebebiyet veren kişi, bu trafik kazasında kendisi de hafif bir şekilde yaralanmış olabilir. Bu durumda failin söz konusu şahsi cezasızlık sebebinden yararlanamayacağı ortadadır. Ancak, söz konusu fıkra hükmü karşısında, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak araç kullanmak suretiyle bir başkasının hafif ve kendisinin ise ağır bir şekilde yaralanmasına sebebiyet veren kişi-

³⁶⁸ Aynı evde anne ve babaları ile birlikte yaşayan kardeşler A ve B, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte ağaç keserler. B, kesilen ağacın bir parçasının kafasına isabet etmesi sebebiyle beyin kanaması sonucu ölür. A’dan on yaş büyük olan B evlidir ve iki çocuk sahibidir. B’nin ölümünden sonra eşi ve çocuklarının geçimini A sağlar. B’nin çeşitli kişi ve kuruluşlara olan borçları A tarafından ödenir. Diğer aile bireyleri gibi B’nin ölümünden dolayı A da çok üzülür. Yargıtay, bu olguların yanı sıra, A’nın cezalandırılmasının B’nin dul kalan eşi ve çocuklarının geçimini sağlama bakımından büyük bir sıkıntıya sebebiyet vereceği gerekçeyle, TCK’nın 22. maddesinin altıncı fıkrası hükmüne istinaden A hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dolayı cezaya hükmolunmaması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur: 9.CD, 30.12.2008, E. 2008/18994, K. 2008/14573 (YKD, Nisan 2009, sh. 784).

³⁶⁹ Nitekim Doktrinde bazı yazarlar, bu durumda hakime ceza vermemek veya cezada indirim yapmak konusunda takdir yetkisinin verilmesinin daha doğru olacağı fikrindedir: YARSU-VAT/ BAYRAKTAR ve diğerleri, sh. 294; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 2. bası, sh.275.

nin bu şahsi cezasızlık sebebinden yararlanıp yararlanamayacağı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır³⁷⁰.

³⁷⁰ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **23.11.2010** tarihli ve E. 2010/9-196, K. 2010/228 sayılı Kararında TCK'nın 22. maddesinin altıncı fıkrası hükmünün uygulanması koşullarına ilişkin olarak şu genel açıklamalara yer verilmiştir:

"5237 sayılı Yasanın 22. maddesinin 6. fıkrasında, taksirli hareket sonucu meydana gelecek neticenin münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açması durumunda, taksirle hareket eden faile ceza verilmeyeceği düzenlenmiştir.

Fıkarda taksirli suçlar açısından "**bir şahsi cezasızlık hali**" düzenlenmiştir. Şahsi cezasızlık hallerinin bulunduğu durumlarda aslında bir suç vardır, bunun yanında failin kusurlu olduğu da kabul edilebilir, ancak yasa koyucu izlediği suç siyaseti gereği bu hali, cezasızlık sebebi saymış, buna bağlı olarak da 5271 sayılı CYY'nın 223. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde "**ceza verilmesine yer olmadığına**" hükmedileceğini hüküm altına almıştır.

22. maddenin 6. fıkrasında yer alan düzenlemenin kapsamının belirlenmesi bakımından uygulamada sorunlarla karşılaşıldığı ortadadır. Bu konudaki tartışmaların genellikle, "fail ile mağdur arasındaki yakınlığın hangi düzeyde olması gerektiği" ve "olay nedeniyle failin hangi ölçüde zarar görmesi gerektiği" konularında yoğunlaştığı görülmektedir.

Düzenlemeye bakıldığında; söz konusu şahsi cezasızlık nedeninin uygulanabilmesi için her somut olay açısından ayrıca değerlendirilmesi gereken iki temel koşulun bulunması gerektiğinden bahsedilebilir:

1-Basit taksirle işlenmiş bir suç bulunmalıdır:

5237 sayılı TCY'nın 22. maddesinin 6. fıkrasının ilk cümlesinde; "taksirli hareket sonucu neden olunan netice"den bahsediliyor olması, sözkonusu **şahsi cezasızlık sebebinin** sadece taksirli suçlarda uygulanabileceğini göstermektedir. Doğrudan kast, olası kast veya kast taksir kombinasyonu ile işlenen suçlarda bu hüküm uygulanamaz. Bilinçli taksirin varlığı halinde ise; aynı fıkranın "bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir" şeklindeki son cümlesi uyarınca, şahsi cezasızlık hali değil, "**cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep**" sözkonusu olabilecektir.

2-Meydana gelecek netice, "münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından" etkili olmalıdır:

Buna göre, failin taksirli hareketiyle neden olduğu netice, hem bizatihi kendisi bakımından acı ve ızdırap doğurmalı, hem de failin cezalandırılması fail ve ailesi bakımından **artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağduriyete** yol açmalıdır.

Görüldüğü gibi bu koşul, üç ayrı hususu içermektedir:

Bunlardan birincisi, "failin kendi taksirli eyleminden ağır düzeyde etkilenmiş olması", başka bir deyişle, failin kendi eyleminin mağduru durumuna düşmesidir. Burada failin uğradığı mağduriyet, maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Hangi mağduriyetin cezaya hükmedilmesini gereksiz kılacağı ise somut olaya göre belirlenmelidir.

İkincisi, failin taksirli eyleminden "ailevi durum" itibarıyla da etkilenmesidir. Bu koşul, fail ile taksirli suçun mağduru arasında belli derecedeki yakınlığı ifade etmektedir. Bu anlamda, üzerinde durulması gereken husus akrabalığın derecesinden çok "aile" kavramıdır. Çünkü, yasa koyucu belli derecede akrabalığı ifade eden herhangi bir kavramı değil özellikle "ailevi" kavramını tercih etmiş ve bir manada faille, mağdur arasında "aynı aileden olma ilişkisini" aramıştır.

...

Üçüncü husus ise; taksirli suçtan "münhasıran failin", kişisel ve ailevi hayatının etkilenmiş olmasıdır:

Buradan anlaşılması gereken; taksirli hareket sonucu ailesinden birisinin zarar görmesi nedeniyle failin ziyadesiyle etkilendiği **olayda, faille ailevi ilişkisi bulunmayan başka bir kişinin zarar**

F. “Bilinçli Taksir” Kavramı

Ceza hukukunda klasik suç teorisinin etkisiyle kastın bilme ve isteme unsurlarından oluştuğunun kabulünün sonucu olarak; taksir, “bilinçli taksir”³⁷¹ ve “bilinçsiz (‘‘adi’’) taksir”³⁷² olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yukarıdan beri taksir kavramıyla ilgili olarak yaptığımız bütün açıklamalar, bu ayırımda “bilinçsiz taksir”e tekabül etmektedir.

Burada sorun “bilinçli taksir” kavramıyla neyin anlatılmak istendiğinin ortaya konulmasından ibarettir. Söz konusu “bilinçli taksir”le neyin anlatılmak istendiğini anlayabilmek için olası kastın anlam ve sınırını göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

21. madde altında izah edildiği gibi, olası kast halinde, suçun kanunî tanımındaki maddi unsurların gerçekleşebileceği, fail tarafından *öngörülmektedir*. Kişi işlediği fiilin bazı neticelerin oluşumuna *muhtemelen* sebebiyet vereceğini öngörmektedir. Başka bir ifadeyle, olası kast halinde, gerçekleşmesi muhtemel addedilen neticelere ilişkin bir *kabullenme* söz konusudur; kanunî tarife uygun neticenin gerçekleşmesi, *olayın seyrine bırakılmaktadır*. Kişi, neticenin gerçek-

görmemesidir. Fail ve ailesi dışında bir kişinin de zarar gördüğü olaylarda ise bu fıkra hükmü uygulanamaz. Ancak başkalarının zarar görmesinden maksat, başkalarının dolaylı olarak etkilenmesi değil, **olay sırasında bizzat zarar görmesidir.** Buna göre, örneğin, olay sırasında eşinin yanında akrabası olmayan bir kişinin de öldüğü ya da yaralandığı durumlarda fail bu fıkradan yararlanamayacak, buna karşılık sadece eşinin öldüğü durumlarda, eşinin diğer akrabalarının bu olay nedeniyle üzülecek olmaları failin bu fıkradan yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; yasa koyucunun “münhasıran failin kişisel ve ailevi” durumundan bahsetmiş ve “kişisel” ile “ailevi” kelimelerinin arasına “ve” bağlacını koymuş olması, **ikinci koşulun gerçekleşebilmesi için belirtilen üç hususun da birlikte bulunmasının zorunlu olduğunu** açıkça göstermektedir. Bunun dışında, taksirli fiil sonunda, örneğin failin yakınının ölmesine rağmen kişisel ilişkilerinin zayıflığı nedeniyle bundan ailevi durum itibarıyla etkilenmediği ya da ailesinden olmayan ancak tüm hayatının akışını etkileyecek şekilde iş ortağının öldüğü veya failin yakını dışında başka kişilerin de zarar gördüğü durumlarda ise bu fıkra hükmü uygulanamayacaktır.

...

Açıklandığı üzere; ikinci koşulun oluşabilmesi için, meydana gelen taksirli olayda, olayın mağdurunun faille aynı aileden olan bir kişi olması, failin bu olay nedeniyle kişisel olarak mağduriyet yaşamaması ve bu olay nedeniyle başka bir kimsenin de zarar görmemiş olması gerekmektedir.

Sanıkla ölen eşi arasında düzenli bir aile birliğinin mevcut olduğu somut olayda, olayın mağdurunun faille aynı aileden olduğunda kuşku bulunmamakta ise de; “ölenin” failin yakın akrabası veya ailesinden biri olması bu “şahsi cezasızlık nedeninin” uygulanması için tek başına yeterli olmayıp diğer iki hususun da birlikte gerçekleşmesi şarttır.

...

Sanığın eşinin ölümü dışında başka bir kimsenin doğrudan zarar görmediği olayda, ölenin anne, baba ve kız kardeşinin de üzülmüş veya psikolojik olarak etkilenmiş olmaları, başkalarının da zarar gördüğü anlamına gelmeyeceğinden, bu nedenle “olaydan münhasıran failin etkilenmiş olması” koşulu ihlal edilmiş olmaz.”

³⁷¹ “Luxuria”.

³⁷² “Negligentia”.

leşmesini muhtemel addetmekle birlikte, bunun *gerçekleşmemesi için özel bir çaba göstermemektedir*. Kanunî tarife uygun neticenin meydana geleceği muhtemel addedilmesine rağmen, fail fiili işlemekten geri kalmamaktadır.

Aslında “bilinçli taksir” halinde de kanunî tarife uygun fiilin işlenmesi muhtemel addedilmektedir.

Olası kasttan farklı ve fakat bir taksir şekli olarak “bilinçli taksir” kavramını kabul eden görüş, bu taksir şekli açısından kanunî tarife uygun bir fiilin gerçekleşeceğinin muhtemel addedilmesinin yanı sıra, başka bir kıstasa ihtiyaç duymuştur. Bu kıstas, olası kastın tanımıyla sıkı bir bağlantı içindedir. Bazı yazarlar, olası kasta nazaran “bilinçli taksir”de gerçekleşmesi *muhtemel addedilen neticenin gerçekleşmesinin istenmemiş olmasını* belirleyici kıstas olarak görmektedirler³⁷³. Nitekim Avusturya Ceza Kanununda şöyle bir tanıma yer verilmiştir:

“Kişi, belli bir vakıanın gerçekleşmesini muhtemel addetmekle beraber, bunun gerçekleşmesini arzu etmiyorsa, (bilinçli) taksirle hareket etmektedir.” (§6, f. 2)

Ancak, işaret etmek gerekir ki; olası kastla hareket eden kişi de kanunî tarife uygun fiilin gerçekleşmesini “arzu” etmemektedir; aksine, bunun gerçekleşmesi sadece kabullenilmektedir.

Kanunî tarife uygun fiilin gerçekleşmeyeceğini ümit etmek dahi bu konudaki ayırıcı kıstası oluşturmaz. Çünkü, şansa bağlı bir neticeyi ümit etmek, kanunî tarife uygun fiilin gerçekleşmesine katlanma halinde de mümkündür³⁷⁴.

“Bilinçli taksir”le ilgili olarak şu şekilde bir açıklamaya da yer verilmiştir: Suç teşkil eden belli bir fiilin gerçekleşmesi muhtemel addedilmekle beraber; fail neticenin meydana gelmeyeceğine *yükümlülüklerine aykırı bir şekilde* güven beslemektedir. Bilinçli taksirde, gerçekleşmesi muhtemel addedilen fiilin gerçekleşmeyeceğine, kişi yükümlülüklerine aykırı ve özensiz bir şekilde güvenmektedir^{375,376,377}.

³⁷³ İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 191 vd., 194; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 979, 982; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 335; SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 426; MAHMUTOĞLU, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXIII(2005), sayı 1-2, sh. 88.

³⁷⁴ ROXIN, Lehrbuch(1), § 12, kn. 27.

³⁷⁵ SCHROEDER, 241/242, 261/262; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, Genel Hükümler (13), sh. 458 vd.

³⁷⁶ “Bilinçli taksirde gerçekleşen sonuç, fail tarafından öngörüldüğü halde istenmemiştir. Gerçekten neticeyi öngördüğü halde, şansına veya başka etkenlere, hatta kendi beceri veya bilgisine güvenerek hareket eden kimsenin tehlikelilik hali, bunu öngörememiş olan kimsenin tehlikelilik hali ile bir tutulamayacaktır. Neticeyi öngören kimse, ne olursa olsun bu sonucu meydana getirecek harekette bulunmamakla yükümlüdür.

Türk Ceza Kanununun 21. maddesinin ikinci fıkrasında; “öngörmesine rağmen, fiili işlemesi” şeklinde tanımlanıp başkaca ayırıcı unsura yer verilmeyen olası kast ile aynı kanunun 22. maddesinin üçüncü fıkrasında; “öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana

Kanımızca, “bilinçli taksir”, kast kapsamında isteme unsuruna yer verilmiş olmasından kaynaklanan izah gücünü aşmak için ortaya atılmış olan bir kavramdır. Halbuki, 21. madde kapsamında kast kavramıyla ilgili olarak yapmış bulunduğumuz açıklamalar göstermektedir ki; kast, bir suçun kanunî tarifindeki maddi unsurların somut olayda gerçekleştiğini bilmeyi ifade etmektedir. Buna karşılık istemek, kastın bir unsuru değildir. İstemek, yani irade, işlenen suçla ilgili olarak failin kusurunun tespiti bağlamında göz önünde bulundurulmalıdır.

gelmesi halinde bilinçli taksir vardır" biçiminde tanımlanan bilinçli taksirin karıştırılacağı hususu öğretide dile getirilmiş, kanun koyucu da madde metninde yer vermediği "kabullenme" ölçüsünü aynı maddenin gerekçesinde; "olası kast halinde suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda gerçekleşeceği öngörülmesine rağmen, kişi fiili işlemektedir, diğer bir deyişle, fail unsurların meydana gelmesini kabullenmektedir" şeklinde açıklamak suretiyle, olası kastı bilinçli taksirden ayıracak kıstası ortaya koymuştur.

...

Gerek olası kast, gerekse bilinçli taksirde netice fail tarafından öngörülmektedir. Bilinçli taksirde, öngörülen neticenin gerçekleşmeyeceği ümit edilmekte, olası kastta ise bu netice fail tarafından göze alınmakta ve kabullenilmektedir. Olası kastta fail öngördüğü neticenin meydana gelmesini kabullenerek, sonucun meydana gelmemesi için herhangi bir önlem almazken, bilinçli taksirde fail neticeyi öngörmesine rağmen, şansa veya başka etkenlere, hatta kendi bilgi veya becerisine güvenerek öngörülen sonucun gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket etmektedir.”: CGK, **10.5.2016**, E. 2014/1-200, K. 2016/250. Ayrıca bkz. CGK, **15.3.2016**, E. 2014/12-779, K. 2016/136; CGK, **31.3.2015**, E. 2014/1-619, K. 2015/80.

³⁷⁷ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**, **14.06.2011** tarihli ve E. 2011/9-110, K. 2011/123 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, doğru olmayan bir değerlendirmeye bilinçli taksirle öldürme suçunun işlendiği yönünde içtihatla bulunmuştur:

Karara konu teşkil eden olayda, sanık, 24.04.2007 günü, saat 19.40 sıralarında, sevk ve idaresindeki ... plakalı Renault Kango tipi aracı ile, ondört metre genişliğinde, asfalt kaplama, yol şerit çizgileri çizilmiş, orta refüjle bölünmüş, zemini kuru, eğimsiz, düz, havanın açık, olay gün ve saati itibarıyla gündüz sayılan bir zaman dilimi içerisinde, trafik ışıklarının faal ve işaret levhalarının tamam olduğu D-100 Devlet Karayolu üzerinde, Hendek istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde iken, kaza mahalli olan ışıklı kavşağa geldiğinde, aşırı sürati, dikkatsiz ve tedbirsiz davranışı nedeniyle, kavşakta kendi yönündeki araçlara yanmakta olan kırmızı ışığı geç fark eder ve hemen aracın frenine basar; ancak aşırı hızla seyretmesi nedeniyle otuzbeş metrelik fren izine rağmen duramayarak aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeder. Orta refüje kadar fren tertibatıyla giden araç, orta refüje çarpıp orta refüjü aşarak karşı yönde, Sakarya istikametinden Hendek istikametine seyir halinde bulunan ve o sırada, kavşakta kendilerine yanan kırmızı ışıkta beklemekte olan araçlardan, ilk olarak SÇ'nin kullanmakta olduğu araca çarpar. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen bu araç, kendisine göre sağ tarafta ve yine kırmızı ışıkta beklemekte olan kamyonun sol yan kısmına çarpar. Aşırı sürati nedeniyle duramayan sanığın aracı, yine kırmızı ışıkta beklemekte olan iki araca daha çarpar ve durur. Kazada, sanığın ilk olarak çarptığı aracın içerisinde bulunan araç sürücüsü SÇ ile aynı araçta bulunan babası AÇ ölür, AÇ ile SÇ yaralanır.

Yargıtay bu olayda sanığın, “**neticeyi öngörmesinin gerekmesi nedeniyle**,” “**bilinçli taksir**”le hareket ettiğini kabul etmiştir. Bilinçli taksirin varlığı için, failin neticeyi öngörmüş olması ve ancak, öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi hususunda tecrübelerine güvenmesi ve elinden gelen gayreti sarf etmesi gerekmektedir. Oysa kararda, gerekçe olarak “**neticeyi öngörmesi gerekmesi nedeniyle**” denilerek, gerçekleşen neticenin **öngörülmemiş olduğu** kabul edilmektedir. Öngörülebilir olmakla birlikte öngörülmeyen netice ile ilgili olarak bilinçli taksirin varlığı kabul edilemez.

Örneğin, yoğun sisin görüş mesafesini oldukça daraltmış olmasına rağmen, motorlu tekneyle boğazın bir yakasından diğer yakasına yolcu taşımaya teşebbüs eden kişi, bu şartlarda bir deniz kazasına sebebiyet verebileceğini muhtemel addeder; ancak tecrübelerine güvenerek, “bir şey olmaz” düşüncesiyle tekneye yolcu alarak boğazda sefere çıkar. Keza, soğuk bir kış günü yolun buz tutabileceğini muhtemel addetmesine rağmen, yolcu yüklü aracın tekerlerine zincir takmaksızın kendisine güvenerek sefere çıkan sürücü, bir trafik kazasına ve neticede bir veya birkaç yolcunun yaralanmasına veya ölümüne sebebiyet verir. Bu olaylarda fail, fiilin sebebiyet verebileceği neticeleri öngörür; ancak, tecrübelerine güvenerek, “bir şey olmaz” düşüncesiyle fiili işlemekten kendisini alıkoymaz. Bu nedenle, her iki örnekte de aslında *olası kastla* işlenmiş yaralama veya öldürme suçları söz konusudur.

Ancak, belirtmek gerekir ki, bazı durumlarda, suçun olası kastla işlenmesine rağmen, failin zorunluluk halinde olması ve dolayısıyla, irade yeteneğinin bulunmaması nedeniyle kusurundan söz edilemez.

Failin, fiilin sebebiyet verebileceği neticeleri öngörmesine rağmen, kurallara uygun davranmasının kendisinden beklenemediği durumlarda, cezalandırılması cihetine gidilemez. Ancak, bu durumda, gerçekleştirdiği fiil haksızlık teşkil etme özelliğini muhafaza eder. Böyle bir durumda failin, kurallara uygun davranması kendisinden beklenemediği için, kusurundan söz edilemez³⁷⁸. Kişi, sebebiyet verebileceği neticeleri öngörmesine rağmen, kurallara aykırı bir davranışta bulunmaktadır, davranış normlarına aykırı bir fiil işlemektedir. Ancak, irade kabiliyetinin bertaraf edildiği veya zayıfladığı durumlarda, bu öngörüye rağmen, işlediği fiilden dolayı kişinin kusursuz olduğunu veya kusurunun azalmış olduğunu kabul etmek gerekecektir.

Örneğin, gerekli tıbbi müdahalede bulunulması için ağır bir hastayı bir an evvel hastaneye kavuşturmaya çalışan araç sürücüsü aracı yerleşim bölgesinde azami hız sınırının çok üstünde sürer. Bu suretle azami hız sınırının üzerinde vasıta kullanan şoför, sonuçta bir kişiye çarparak ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet verir. Bu örnek olayda hızlı vasıta süren araç sürücüsü trafik kurallarına aykırı hareket ettiğinin bilincindedir ve dolayısıyla, bu fiili neticesinde bir başkasının ölebileceğini veya yaralanabileceğini öngörür. Her ne kadar trafik kurallarını ihlâl ettiğinin şuurunda ise de, her ne kadar fiilin sebebiyet verebileceği neticeleri öngörmekte ise de; araç sürücüsünün, içinde bulunduğu *zorunluluk hali* dolayısıyla trafik kurallarına uygun olarak davranışlarını yönlendirebilme (irade) yeteneği bulunmamaktadır. Bu itibarla, bir insanın ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet verilmesi suretiyle bir haksızlık gerçekleşmiş olmasına rağmen; araç sürücüsünü bu haksızlıktan dolayı muaheze edememekteyiz, kınayamamaktayız, kısacası kusurlu addedememekteyiz³⁷⁹.

³⁷⁸ ROXIN, Lehrbuch(1), 24/107.

³⁷⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 101/102; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 2. bası, sh. 256; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 242/243.

Aynı şekilde, örneğin hava korsanları bir yolcu uçağını içindeki yolcularla birlikte kaçırlar. Uçak, yakıt ikmali için bir havaalanına indirilir. Burada yolcuların hava korsanlarının elinden kurtarılmasını temin için uçağa operasyon düzenlenir. Özel eğitim görmüş güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yolcuların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için gerekli bütün dikkat ve ihtimam gösterilir. Ancak, operasyon sırasında uçak infilak eder, uçağın içindeki bütün yolcular ve mürettebat, korsanlarla birlikte yanarak ölür.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik görevlileri, bu operasyon sırasında yolculardan veya mürettebattan en azından bir kısmının yaralanabileceğini ve hatta ölebileceğini öngörürler. Ancak, gerekli bütün dikkat ve ihtimamı göstermelerine rağmen korkulan olur.

Bu örnek olayda güvenlik görevlileri yolcuların kurtarılmasına yönelik operasyon sırasında yolculardan en azından bir kısmının yaralanabileceğini ve hatta ölebileceğini öngörmelerine rağmen, fiili (operasyonu) gerçekleştirmekten imtina etmezler. Güvenlik görevlilerinin bu durumda meydana gelen neticeler açısından olası kastla hareket ettiklerini kabul etmek gerekir.

Ancak, olası kastın varlığı güvenlik görevlilerinin bu olaylarda ceza hukuku bakımından zorunlu olarak sorumlu tutulmalarını gerektirmez. Sorumluluk için önemli olan, uçak içinde bulunan yolcuların korsanların elinden kurtarılabilmesi için başka bir çarenin bulunup bulunmamasının tayinidir.

Yolcuların korsanların elinden başka türlü, yani daha az bir zararla kurtulma imkânının bulunmasına rağmen, bir kısım yolcuların yaralanması ve hatta ölmesi sonucunu ortaya çıkarabilecek bu operasyonun yapılması durumunda; güvenlik görevlilerinin, olası kastla sebebiyet verdikleri yaralanma veya ölüm neticelerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiği kanısındayız. Bu ihtimalde, güvenlik görevlilerinin yolcuların zarar görmemesi için gerekli bütün dikkat ve ihtimamı göstermiş olmalarının kanımızca ceza sorumluluğu üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

Buna karşılık, yolcuların kurtarılabilmesi için tek çarenin operasyon düzenlenmesi olması durumunda; *zorunluluk hali* dolayısıyla, güvenlik görevlilerinin ceza sorumluluğu cihetine gidilemez. Başka bir deyişle, bu durumda meydana gelen neticeler açısından olası kastın varlığına rağmen; *zorunluluk hali* dolayısıyla güvenlik görevlilerinin kusurundan söz edilemez³⁸⁰.

Dikkat edilmelidir ki, bu açıklamalarımız, gerçekleştirilen operasyon dolayısıyla yolculardan bir kısmının yaralanması veya ölmesi haline ilişkindir. Güvenlik

³⁸⁰ İşaret etmek gerekir ki; *zorunluluk hali*, Türk ceza hukukunda bir “hukuka uygunluk sebebi” olarak kabul edilmektedir. Ancak, biz, *zorunluluk halini* sadece *kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep* olarak mütalâa etmekteyiz (Bkz. ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 50 vd.; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 226 vd., 263 vd.). Nitekim, 25. maddesinin gerekçesinde, yeni TCK’nın *zorunluluk halini kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden* olarak kabul ettiği, açık bir şekilde vurgulanmıştır.

görevlilerinin hava korsanlarını etkisiz hale getirmek için bu kişilere karşı ika ettikleri fiillerin, *görevin ifası hukuka uygunluk sebebinin* şartlarıyla bağlantılı olarak bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir.

Bütün bu anlattıklarımızdan çıkan sonuç şudur: “Bilinçli taksir”, aslında kastın bilme ve isteme olmak üzere iki unsurunun olduğu yönündeki klasik suç teorisinin etkisiyle ortaya atılmış olan bir kavramdır. Halbuki, kanımızca irade, kastın bir unsuru değildir. Kast, bir suçun bütün maddi unsurlarının somut olayda gerçekleştiğinin bilincinde olmayı ifade etmektedir. Bu nedenle “bilinçli taksir”le bağlantılı olarak verilen bütün örnek olaylarda, aslında olası kast mevcuttur³⁸¹.

Fakat, klasik suç teorisinin etkisiyle yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısında “bilinçli taksir”e ilişkin hükme yer verilmiştir (TCK Tasarısı, m. 21, f. 3). Bu hükmün metinden çıkarılması yönündeki düşüncemiz, TBMM Adalet Alt Komisyonunda kabul görmemiştir. Bu düşüncemizin kabul edilmemesinin gerekçesi olarak, Hükümet Tasarısındaki söz konusu hükmün kısa bir süre önce (8.1.2003 t. ve 4785 s. Kanunla) 765 s. TCK’nın 45. maddesine son fıkra olarak eklenmesi gösterilmiştir. Hükümet Tasarısındaki söz konusu hüküm, aynen yeni TCK’ya alınmıştır:

“Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.” (m. 22, f. 3)

Madde gerekçesinde, Hükümet Tasarısından esinlenilerek, şu açıklamalara yer verilmiştir:

*“Maddenin üçüncü fıkrasında, bilinçli taksirin tanımı verilmiştir. Bilinçli taksiri basit taksirden ayıran özellik, fiilin neticesinin failce fiilen **öngörülmüş** ve fakat **istenmemiş** olmasıdır. Bilinçli taksir hâlinde hükmedilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılacaktır. Böylece bilinçli taksir, iş kazalarını, trafikte meydana gelen taksirli suçları önlemek bakımından caydırıcı etki yapacak ve suçların önlenmesinde yarar sağlayacaktır.”*

Ancak, belirtmek gerekir ki, Hükümet Tasarısının bu fıkraya ilişkin gerekçesinde, “kastın bir türü olan ‘gayrimuayyen kastla’ bazen karıştırılan ve kimi Fransız yazarların ‘olası kast’ dedikleri bilinçli taksir”den söz edilmiştir (TCK Tasarısı, m. 21, f. 3 gerekçesi). Dikkat edilmelidir ki, Hükümet Tasarısının gerekçesinde yer verilen bu ifadelerde olası kastla “bilinçli taksir” birbirine karıştırılmıştır. Aslında *olası kast* (*muhtemel kast*, *dolus eventualis*), klasik suç teorisindeki gayrimuayyen kast kavramının karşılığında kullanılmakta olup, kastın bir çeşidini oluşturmaktadır. Halbuki bilinçli taksir, özellikle “isteme” unsuru bakımından olası kasttan ayrılmak istenmiştir. Olası kasttan farklı olarak, *bilinç-*

³⁸¹ ÖZGENÇ, İzzet: *Bilinçli Taksir*, in: Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı (Galatasaray Üniversitesi yayını), İstanbul, 2004, sh. 697 vd. Ayrıca bkz. BOZBAYINDIR, Olası Kast Kavramı ve Sınırları, sh. 275 vd.

li taksirde, fail öngördüğü neticenin gerçekleşmesini istememektedir ve gerçekleşmemesi için bütün gayretini göstermektedir ve fakat, korkulan olmaktadır.

Bu bakımdan, yukarıda vermiş bulunduğumuz örnek olaylarda yeni TCK'nın bu düzenlemesi karşısında, olası kastın değil, bilinçli taksirin varlığını kabul etmek gerekir.

Örneğin, yoğun sisin görüş mesafesini oldukça daraltmış olmasına rağmen, motorlu tekneyle boğazın bir yakasından diğer yakasına yolcu taşımaya teşebbüs eden kişi, bu şartlarda bir deniz kazasına sebebiyet verebileceğini muhtemel addeder; ancak tecrübelerine güvenerek, tekneye yolcu alır ve boğazda sefere çıkar. Görüş mesafesinin darlığı nedeniyle bir başka araca çarparak, yolculardan bir kısmının ölümüne veya yaralanmasına neden olur.

Keza, soğuk bir kış günü yolun buz tutabileceğini muhtemel addetmesine rağmen, yolcu yüklü aracın tekerlerinde zincir olmaksızın sefere çıkan sürücü, bir trafik kazasına ve neticede bir veya birkaç yolcunun yaralanmasına veya ölümüne sebebiyet verir.

Bu olaylarda fail, fiilin sebebiyet verebileceği neticeleri öngörür; ancak, tecrübelerine güvenerek, fiili işlemekten kendisini alıkoymaz. Kişinin, bir kazaya sebebiyet vermemek ve yolculardan herhangi birinin yaralanmaması için dikkat ve özen göstermesine rağmen, korkulan gerçekleşir. Yeni TCK'nın düzenlemesi karşısında, bu gibi olaylarda *bilinçli taksirin* varlığını kabul etmek gerekir³⁸².

³⁸² Yargıtay, yeni kararlarıyla bilinçli taksire ilişkin olarak mustakar içtihat oluşturma eğilimi içindedir.

“Taksir ile bilinçli taksir arasındaki yegane fark; taksirde failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörmemesi, bilinçli taksir halinde ise bu neticeyi öngörmüş olmasıdır. Bilinçli taksirde gerçekleşen sonuç fail tarafından öngörüldüğü halde istenmemiştir. Gerçekten neticeyi öngördüğü halde, sırf şansına veya başka etkenlere, hatta kendi beceri veya bilgisine güvenerek hareket eden kimsenin tehlike hali, bunu öngörmemiş olan kimsenin tehlike hali ile bir tutulamaz; neticeyi öngören kimse, ne olursa olsun, bu neticeyi meydana getirecek harekette bulunmamakla özellikle görevlidir.”: CGK, **25.3.2008**, E. 2008/9-43, K. 2008/62. Ayrıca bkz. CGK, **29.3.2016**, E. 2014/12-585, K. 2016/150; CGK, **6.10.2009**, E. 2009/9-189, K. 2009/220; CGK, **11.3.2008**, 2007/9-275, 2008/49.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **6.10.2009** tarihli ve E. 2009/9-189, K. 2009/220 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda;

Ahmet U, yönetimindeki kamyonla, taş ocağından yüklediği dolgu malzemesini 30.3.2006 günü 08.00 -08.30 sıralarında taşıırken, kamyonun kasasından “40x30 cm. ebatlarında” bir taş karayoluna düşer ve yol kenarında yayalara ayrılan bölümde yürümekte olan Ayşe K'ya çarparak ölümüne neden olur.

Dolgu malzemesi yüklü kamyonun üzeri branda ile örtülü değildir ve kamyon “kasa yüksekliğini geçecek şekilde” yüklenmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda “*karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapılması*” (m. 65, f. 1, bent c) ve “*yükün karayoluna düşecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi*” (m. 65, f. 1, bent g) yasaklanmıştır. Buna rağmen araç sürücüsü, kamyonu yüklediği taşların düşmemesi için üzerini kapatmak gibi gerekli tedbirleri almamıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu olayda kamyon sürücüsünün **bilinçli taksirle** ölüme sebebiyet vermekten dolayı cezalandırılması gerektiği içtihadında bulunmuştur.

Ancak, bu karara ilişkin **gerekçe** kendi içinde **çelişkilidir**. Şöyle ki:

Kararda, Karayolları Trafik Kanununun 65. maddesinin 1. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki yasağa rağmen, kamyonuna kasasını aşacak şekilde dolgu malzemesi yükletip, bu yükün üzerini kapatmadan şehirlerarası yola çıkması halinde, kamyondaki taşların düşebileceğinin, düşen taşların araçlara veya doğrudan kişilere çarparak, kişilerin ölümüne, yaralanmasına veya malvarlığının zarar görmesine sebebiyet verebileceğinin “*kamyon sürücüsü sanık tarafından öngörülmesi gereken bir husus*” olduğu belirtilmiştir. Bu ifadeye göre, sanık kamyon sürücüsü, kamyonu ile belirtilen şekilde yüklü vaziyette trafiğe çıkmasının sebebiyet verebileceği neticeleri **öngörmemiştir**. Ancak Kararda, “*buna rağmen sözü edilen hatalı taşıma yönteminin zaman ve emekten tasarruf sağlaması ve bu yöntemle ilgili geçmiş deneyimlerinin şanslı sonuçlanması gibi nedenlerle, sanığın bu riski göze aldığı anlaşıldığından, sanığın meydana gelen neticeyi 5237 sayılı TCY’nın 22/3. maddesi kapsamında öngördüğünün, ancak istemediğinin, dolayısıyla da olayda bilinçli taksir halinin bulunduğu kabulü gerekir.*” sonucuna varılmıştır.

Yargıtay, bu tür olaylarla ilgili içtihatlarında toplumsal ilişkiler bakımından yönlendiricilik görevini de yerine getirmelidir. Karara konu teşkil eden olayda ceza sorumluluğu bakımından sadece kamyon sürücüsü göz önünde bulundurulmuştur. Aslında bu olayda, müteahhit firma yetkililerinin de ceza hukuku bakımından sorumluluğu tartışılmalıydı. Çünkü bu tür olaylarda taşımaya ilişkin kurallara uygun davranma hususunda, kamyon sürücülerinden ziyade, müteahhit firma yetkilileri belirleyici konumda olmaktadır.

Ancak, Yargıtay yeni kararlarından birinde kanımızca olası kastın varlığına rağmen bilinçli taksirin varlığı yönünde içtihatla bulunmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **25.3.2008** tarihli ve E. 2008/9-43, K. 2008/62 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda:

Sanık, kullanmakta olduğu halk otobüsü ile sabah saat 06.00 sularında kazanın meydana geldiği kavşağa yaklaşırken hızını azaltmaz ve geçiş hakkı olan araçların geçmesine imkân vermez. Sanık, “Dur” işareti anlamına gelen ve ancak gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra hareket edilmesi gerektiğini belirten fasıllı kırmızı ışığın kendisine yanıyor olmasına karşın, durmak bir yana hızını dahi azaltmadan kavşağa girmesi, kavşağın ortasındaki ikinci fasıllı kırmızı ışığı da geçtikten sonra kendisine fasıllı sarı ışık yanması nedeniyle kavşağa giren otomobile fren yapma fırsatı bile bulamadan yandan çarpar ve otomobilin 33 metre sürüklenmesine sebep olur. Sanığın kullanmakta olduğu halk otobüsü çarpmanın etkisiyle duramayarak önce orta kaldırımını aşır karşı şeride geçer, sonrasında tekrar kendi şeridine dönerek çarpma noktasına 150 metre mesafede durur. Bu kazada otomobil sürücüsü M ile aracında bulunan U ölür.

Bu olayla ilgili olarak hakkında açılan kamu davasında Esas Mahkemesi, sanığın, **bilinçli taksirle** ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle, 5237 s. TCK’nın 85. maddesinin ikinci fıkrası, 22. maddesinin üçüncü fıkrası e 62. maddesi uyarınca 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK’nın 53. maddesinin altıncı fıkrasına göre cezasının infazından sonra “ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına” hükmetmiştir.

Temyiz üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi, “*olayda bilinçli taksirin koşullarının oluşmadığı*” gerekçesiyle Esas Mahkemesinin kararını bozmuştur.

Esas Mahkemesi, önceki hükmünde direnmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıda özetlemiş olduğumuz ve bizim de katıldığımız gerekçe ile, Esas Mahkemesinin direnme kararının onanmasına karar vermiştir:

2918 s. Karayolları Trafik Kanununa göre, sürücüler,

- a) trafik ışıklarına uymakla (m. 47/B),
- b) kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmakla (m. 52/A),

Bilinçli taksir halinde, “bilinçsiz” taksire göre belirlenen temel ceza (m. 61, f. 1 ve 2), artırılacaktır. Bu artırmanın oranı, 22. maddenin üçüncü fıkrasında belirlenmiştir.

III. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç

Kişi suç teşkil eden bir fiili işlerken, kastettiği neticeden daha ağır veya başka bir netice gerçekleşmiş olabilir. Bir başka ifadeyle; fail, kastettiği neticenin dışında gerçekleşen bu daha ağır veya başka netice açısından kasten hareket etmemiştir. Bu gibi durumlarda *netice sebebiyle ağırlaşmış suç* söz konusudur.

Yeni TCK’nın 23’üncü maddesi, bu ağır veya başka neticeden sorumluluk için, failin bu netice açısından en azından *taksire dayalı kusurunun* varlığını gerekli görmektedir:

“Bir filin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için, bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.”

Bu düzenlemeyle, hukuk sistemimizdeki netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar açısından kusursuz sorumluluk terkedilmiş olmaktadır^{383, 384}.

c) kavşaktaki koşullara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak ve geçiş hakkı olan araçların geçmesine imkân vermekle (m. 57/A),

yükümlüdürler.

“Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik”in 9. maddesinde, fasıllı olarak yanıp sönen sarı ışık, “ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir. (yolver işaret levhası gibi)” şeklinde, fasıllı olarak yanıp sönen kırmızı ışık ise, “dur işareti levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir” biçiminde tanımlanmıştır.

Olayın oluş biçimi göz önünde bulundurulduğunda, “sanığın meydana gelen neticeyi 5237 sayılı TCY’nın 22/3. maddesi kapsamında öngördüğünün ancak istemediğinin, dolayısıyla da olayda **bilinçli taksir halinin bulunduğu kabulü** gerekir.”

Ancak, önemle belirtmemiz gerekir ki, bu kararda, daha önce sanık hakkında Ego Genel Müdürlüğüne “süresiz olarak toplu taşıma araçlarında çalışmama” disiplin cezası verilmiş olması, sanığın kazadan sonra halk otobüsünü olay yerinde bırakarak kaçması, bir süre sonra kullandığı başka bir araç ile kaza yerine hızla gelip duramayıp olay yeri güvenliği için polis tarafından konulan plastik dubalara çarpması, bu nedenle görevli polislerle bir süre tartışması, bir süre sonra kendisinin ölümlü trafik kazasının şüphelisi olduğunu anlayan polislerce durması yönünde kendisine yapılan ihtarlar karşın durmayarak aracıyla kaçması, takip edilirse de süratli olması nedeniyle yakalanamaması gibi hususlar, sanığın kusurunun belirlenmesinde dikkate alınmışlardır. Bu yaklaşımın doğru olmadığını belirtmek gerekir. Belirtilen hususlar, sanık hakkında hükümlenilecek **cezanın sadece bireyselleştirilmesi bağlamında** dikkate alınabilirler.

³⁸³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için Türk hukukunda önemli bir kaynak olarak bkz. KAYMAZ, Seydi: *Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma*, Ankara, 2009, “Önsöz” ve ayrıca sh. 3 vd., 107 vd. Ayrıca bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, Genel Hükümler (13), sh. 471 vd.; ERDAĞ, Ali İhsan: *Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç (Erfolgsqualifi-ziertes Delikt)*, Ankara, Nisan 2011; DOĞAN, Koray: *Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar*, Ankara, 2011; ÖZENBAŞ, Nazmiye: *Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Ceza Sorumluluğunun Esası*,

Ankara, 2012; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 2. bası, sh. 277 vd. *Hafizoğulları*, söz konusu hükmle Türk hukukunda bir “taksir karinesi” oluşturulduğunu iddia etmektedir. Söz konusu madde hükmüne ilişkin tutarsız eleştiriler için bkz. HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 258; YARSUVAT/BAYRAKTAR ve diğerleri, sh. 294.

³⁸⁴ Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suçlara ilişkin olarak **Yargıtay Ceza Genel Kurulunun** vermiş bulunduğu **16.2.2010** tarihli ve E. 2009/1-209, K. 2010/29 sayılı kararını aşağıya iktibas ediyoruz:

“765 sayılı TCK’nın 452. maddesinde yer alan hükmün benzeri bir düzenlemeye, objektif sorumluluk esasının terk edilmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’da yer verilmemiştir. Suçu, “**yasada tanımlanmış bir haksızlık**” olarak öngören **yeni suç teorisinde**, bir hareketi yapan kişi, bu hareketin tüm sonuçlarından her koşulda sorumlu tutulmamakta, bir başka anlatımla “**kusursuz sorumluluk**” **terkedilmiş olmaktadır**. 765 sayılı TCK’daki objektif sorumluluk esasının yerine 5237 sayılı TCY’nda **haksızlığın bir gerçekleştirilme şekli olarak kast-taksir kombinasyonuna**, yani **netice sebebiyle ağırlaştırılmış suçlara** yer verilmiştir. Bu nedenle uyumsuzluğun çözümü için, **5237 sayılı TCK’nın hazırlanmasında esas alınan suç teorisinde**, suçun manevi unsurları arasında gösterilen kast-taksir kombinasyonu, yani netice sebebiyle ağırlaştırılmış suç üzerinde durulmalıdır.

5237 sayılı TCK’nın “*Netice sebebiyle ağırlaştırılmış suç*” başlıklı 23. maddesi,

“(1) Bir failin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.”

şeklinde. Buna göre; failin gerçekleştirdiği bir eylemde, **kastettiğinden daha ağır veya başka bir sonucun meydana gelmesi** halinde, sorumlu tutulabilmesi için, netice bakımından en azından taksirle hareket etmiş olması gerekmektedir. Fail, bu sonucun meydana gelmesinden taksirle bile sorumlu tutulmıyorsa, objektif sorumluluğun kaldırılmasının doğal bir sonucu olarak, sadece nedensellik bağının bulunuyor olması, neticeden sorumlu tutulması için yeterli olmayacaktır.

Öğretide, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç, gerçek neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç ve görünüşte ya da gerçek olmayan neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç olarak iki farklı şeklinin bulunduğu kabul edilmektedir. Gerçek neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suçlarda, failin hareketi sonucunda kastettiğinden daha ağır bir netice ortaya çıkmakta olup, gerçekleşen aşırı netice dolayısıyla bağımsız bir suç tipi ortaya çıkmaktadır. Örneğin, yaralama suçunda mağdurun ölmesi, gerçek neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç halidir. Görünüşte neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suçlarda ise, failin hareketi sonucunda suçun oluşması için aranan neticeden başka, niteliği de farklı olan daha ağır bir netice ortaya çıkmakta olup, gerçekleşen aşırı netice dolayısıyla temel suç niteliği aynı kalmakla beraber yalnızca ceza ağırlaştırılmaktadır. Örneğin, cinsel istismar suçunda mağdurun ruh veya beden sağlığının bozulması, görünüşte neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç halidir.

5237 sayılı TCK’nın 23. maddesinde düzenlenmiş bulunan neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suçla ilişkin genel kuralın, özel hükümler arasında kendisine yer bulduğu maddelerin başında gelen TCK’nın 87. maddenin 4. fıkrası;

“(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

şeklinde. Maddede, gerçekleştirilen kasten yaralama eylemi TCK’nın 86. maddesinin 1. veya 3. fıkraları kapsamında bulunur ve bunun sonucunda da ölüm meydana gelirse, en azından taksirle hareket etmiş olmak koşuluyla faile belirtilen cezaların verileceği öngörülmektedir.” Ayrıca bkz. CGK, **14.4.2009**, E. 2008/1-197, K. 2009/93; CGK, **27.12.2011**, E. 2011/1-151, K. 2011/ 290.

“5237 sayılı TCK’nın 23. maddesinde düzenlenmiş olan neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suçla ilişkin genel kuralın, özel hükümler arasında kendisine yer bulduğu maddelerin başında gelen

Örneğin, A, B'yi yaralamak kastıyla hareket eder; ancak, işlediği fiil neticesinde B ölür. Oğlu tarafından kendi haline terk edilen yaşlı ve hasta baba, bakımsızlıktan dolayı ölür. Annesi tarafından cami avlusuna bırakılan bebek, havanın soğuk olması nedeniyle, akciğerlerini üşütür ve kalıcı bir hastalığa yakalanır.

Kusursuz sorumluluk şekli olarak, meydana gelen ağır neticeden sorumluluk hali, Kilise hukukuna dayanır. Kilise hukukundaki “*versari in re illicita*” kuralına göre, hukuka aykırı bir durumda olan, bunun bütün neticelerine katlanmış olur³⁸⁵. Bu halin ceza kanunlarındaki tipik örneğini, kasten yaralama sonucu mağdurun ölmesi hali teşkil etmektedir. Buna göre, kasten yaralama suçunun işlenmesiyle he-

TCK'nın 87. maddenin 4. fıkrasına göre, gerçekleştirilen kasten yaralama eylemi aynı Yasa'nın 86. maddesinin bir veya üçüncü fıkraları kapsamında bulunur ve bunun sonucunda da ölüm meydana gelirse, en azından taksirle hareket etmiş olmak koşuluyla faile belirtilen cezaların verileceği öngörülmektedir.

Bu durum karşısında kasten yaralama neticesinde mağdurun ölmesine ilişkin olarak TCY'nın 87/4. maddesinin uygulanabilmesi için;

- a- Failin yaralama kastı ile hareket etmesi,
- b- Mağdurun TCK'nın 86. maddesinin birinci veya üçüncü fıkrasında düzenlenen şekilde yaralanmış olması,
- c- Failin eylemi ile arasında illiyet bağı bulunacak şekilde mağdurun ölmesi,
- d- Failin meydana gelen ölüm sonucuna ilişkin en az taksir derecesinde bir kusurunun bulunması, koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Buna göre, fail mağduru yaralamak amacıyla hareket etmeli, mağdurun yaralanacağını bilmeli ve bu sonucu istemelidir. Bununla birlikte **fail** mağdurun yaralanmasını değil ölmesini istemiş ve ölüm meydana gelmiş ise kasten öldürmeden; **mağdurun ölebileceğini öngörmesine karşın olursa olsun diyerek bu sonucu göze almış ve kabullenmiş ise, bu durumda da neticesi sebebiyle ağırlaşan suçtan değil, olası kastla öldürmeden sorumlu tutulacaktır.**” CGK, 18.09.2012, E. 2012/1-941, K. 2012/1780.

“Sanığın, annesinin arkasına saklanan kızına vurmak istediği sırada kontrolsüz biçimde savurduğu yumruğun karşısında bulunan annesinin isabet alarak yaralanabileceğini bilmesine rağmen hareketine devam ederek şiddetli bir şekilde savurduğu yumruğun başına isabet etmesi sonucu yaralanan maktulenin kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra aldığı bu darbeye bağlı olarak öldüğü, maktulenin başının arka kısmına isabet eden bu darbenin TCK'nın 86/1. maddesi kapsamında basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği ve yaşamını tehlikeye soktuğu anlaşıldığından, kızını darp etmek suretiyle yaralamak isteyen ancak aralarında bulunan maktulenin de isabet alarak yaralanabileceğini bildiği halde sert bir şekilde savurduğu yumruğunun maktuleye isabeti sonucu yaralanmasına neden olan sanığın kasten hareket ettiğinin kabulü gerekir. Maktulenin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikli olması ve ölüm ile sanığın eylemi arasında doğrudan illiyet bağının bulunması karşısında, TCK'nın 86/3. maddesi yollamasıyla aynı kanunun 87/4. maddesi uyarınca hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.” CGK, 25.2.2014, E. 2013/1-765, K. 2014/92.

Doktrinde bazı yazarlar tarafından “*gerçek – gerçek olmayan (görünüşte) neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar*” ayırımına yer verilmektedir (CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem: *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, 5. bası, İstanbul, 2008, sh. 405). Belirtmemiz gerekir ki, bu ayırımın uygulama bakımından hiçbir pratik sonucu bulunmamaktadır.

³⁸⁵ ERDAĞ, Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç, sh. 11, 15; DOĞAN, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, sh. 30 vd.

deflenenden daha ağır bir netice olarak mağdurun ölmesi halinde, kanunlar kasten yaralama suçunun cezasından daha ağır bir cezanın tatbikini öngörmektedirler. Ancak, Kilise hukukundaki “*versari*” kuralı gereğince, kanunlar, meydana gelen ağır netice açısından failin kusurlu olup olmadığının araştırılmasına gerek hissetmemişlerdir. Sorumluluk alanında bu şekilde meydana gelen aşırı genişliğin, “*uygun illiyet teorisi*”yle sınırlandırılması cihetine gidilmiştir³⁸⁶.

Bu tür düzenlemeler hukukun evrensel prensiplerinden *kusursuz ceza olmaz* (nulla poena sine culpa) kuralına aykırılık arz etmektedir. Dolayısıyla, meydana gelen ağır netice açısından kişinin sorumlu tutulabilmesi için, söz konusu neticeye ilişkin olarak en azından taksir dolayısıyla kusurlu bulunmalıdır. *Kast-taksir kombinasyonunun* söz konusu olduğu bu hallerde, iki kademe mevcuttur. Birinci kademeyi, kasten işlenen temel suç; ikinci kademeyi ise, en azından taksirle sebebiyet verilen ağır netice oluşturmaktadır^{387, 388}.

Örneğin yeni TCK’ya göre, cinsel saldırı veya cinsel istismar sonucunda “*mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.*” (m. 102, f. 5; m. 103, f. 6).

Meydana gelen ağır veya başka netice açısından fail çoğu zaman *olası kastla* hareket eder. Bu durumda, failin olası kastla gerçekleştirdiği ağır neticeden dolayı sorumlu tutulması gerekir. Örneğin, işlenen kasten yaralama fiili sonucunda, kişinin “*duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına*” (m. 87, f. 1, bent a) veya “*yitirilmesine*” (m. 87, f. 2, bent b) sebebiyet verilmiş olabilir; kişi görme, işitme yeteneğini yitirmiş olabilir vs. Kişiye karşı yaralama suçu işlenirken, genellikle bunun sonucunda ağır bir neticenin meydana gelebileceği ihtimali gözönünde bulundurulur. Meselâ gözün, kulağın üzerine sert bir yumruk vuran kişi, bu yumruk neticesinde mağdurun görme veya işitme yeteneğini yitirebileceği ihtimalini gözönünde bulundurur. Yine, çeneye sert bir yumruk vurulması halinde, çenenin veya birkaç dişin kırılabileceği düşünülür. Dolayısıyla, bu gibi durumlarda meydana gelen ağır netice açısından failin *muhtemel kastla* hareket ettiğini söylememiz mümkündür³⁸⁹. Keza, üzerinde deney yapılan kişinin ölmesi (m. 90, f. 5), işkence yapılan kişinin ölmesi (m. 95, f. 4), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması (m. 109, f. 4) hallerinde, gerçekleşen ağır netice açısından kişinin genellikle olası kastının varlığını kabul etmek gerekir.

³⁸⁶ Bkz. JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 235; ROXIN, Lehrbuch I, sh. 210; ÖZGENÇ, Süleyman Arslan Armağanı, 361.

³⁸⁷ GÖSSEL, Karl Heinz: *Dogmatische Überlegungen zur Teilnahme am erfolgsqualifizierten Delikt nach § 18 StGB*, Festschrift für Richard Lange, 1976, sh. 219.

³⁸⁸ Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “*Kavga Suçu*” (TCK., m. 464) *Üzerine Düşünceler*, Yargıtay Dergisi, cilt 19, yıl 1993, sayı 4, sh. 477 vd.

³⁸⁹ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Kast-Taksir Kombinasyonları*, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Süleyman Arslan Armağanı, cilt 6, yıl 1998, sayı 1-2, sh. 345 vd. (360 vd.); aynı yazar: *Gerekçeli Türk Ceza Kanunu*, Ankara, Kasım 2004, sh. 15; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 185 vd.

Gerçekleşen ağır veya başka netice açısından failin (olası) kastı mevcut olmakla birlikte; haksızlığın icrası sırasında bu ağır veya başka neticenin gerçekleşebileceği müşahade edilebilir nitelikte ise; bu neticenin gerçekleştirilmesinden dolayı failin taksirle sorumluluğu cihetine gidilmelidir. Meydana gelen ağır veya başka neticeden dolayı sorumlu tutulabilmesi için, failin bu neticenin oluşumu açısından *en azından taksirinin* mevcut olması gerekir.

Meydana gelen ağır veya başka neticeden failin sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna fail tarafından gerçekleştirilen failin sebebiyet vermesi gerekir. Meydana gelen ağır veya başka neticenin oluşumuna failin icra ettiği fiil sebebiyet vermiş değilse; bu neticeden faili sorumlu tutmamız mümkün olmayacaktır³⁹⁰.

Yeni TCK'nın sisteminde kasten yaralama sonucunda mağdurun ölmesi dolayısıyla *netice sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre* sorumluluk için (m. 87, f. 4); failin, kasten yaralama suçunun temel şeklini oluşturacak ağırlıkta (m. 86) olması gerekir. Buna karşılık, hafif yaralama (m. 86, f. 2) sonucunda (örneğin karın boşluğuna vurulan bir yumruğun etkisiyle) mağdurun ölmesi halinde, meydana gelen ölüm neticesinden ancak *taksirle öldürme suçuna göre* (m. 85, f. 1) sorumluluk söz konusu olabilir^{391,392}.

³⁹⁰ İlginçtir ki; Erem/Toroslu, icra ettiği fiil ile meydana gelen ağır netice arasında illiyet bağlantısının kurulamaması halinde, failin “taksirle adam öldürme”den dolayı cezalandırılması gerektiği fikrindedirler (EREM, Faruk/TOROSLU, Nevzat: *Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler*, 4. bası, Ankara, Kasım-1983, sh. 327).

³⁹¹ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. KAYMAZ, Kasten Yaralama Sonucu Ölümüne Neden Olma, sh. 59 vd.

³⁹² CGK, **10.5.2016**, E. 2014/12-218, K. 2016/256: “Sanığın, olay günü tartıştığı ölene yumruk atıp cebinden çıkardığı kontrol kalemi ile sol kaşının üstüne doğru vurup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde onu yaraladığı, kendisinde kronik kalp damar hastalığı mevcut bulunan YN'nin bu olayın meydana getirdiği efor ve stresin tesiri ile fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı, gelişen kalp durması ve beynin oksijensiz kalması sonucu olaydan otuz beş gün sonra hastanede vefat ettiği olayda, sanığın eyleminin TCK'nın 86/2. maddesi kapsamında kalan kasten yaralama olduğunda kuşku bulunmamakta olup bu nedenle de eyleminin TCK'nın 87/4. maddesine uyduğunu kabule kanunen imkan bulunmamaktadır.

Sanık öldürme kastı ile hareket etmemiş, ancak kendisinden on dokuz yaş büyük olan 61 yaşındaki öleni itekleyerek baş bölgesine yumruk atıp, kontrol kalemi ile şiddetli biçimde vurarak yaralamak suretiyle kalp krizi geçirebileceğini öngörmüş, fakat neticeyi yani ölümü arzulamamıştır. Bu nedenle sanığın eyleminin taksirle ölüme neden olmak suçunu oluşturduğunu kabul eden yerel mahkeme direnme hükmünde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.” Ayrıca bkz. CGK, **1.3.2016**, E. 2013/12-495, K. 2016/97; CGK, **26.1.2016**, E. 2013/12-371, K. 2016/39.

CGK, **14.4.2009**, E. 2008/1-197, K. 2009/93: “Hükümlünün, öleni itmesi ile meydana gelen ölüm arasında nedensellik bağının bulunduğu ve hükümlünün öleni eliyle iteklemesi eyleminin 5237 sayılı TCY'nın 86/2. maddesi kapsamında kalan kasten yaralama olduğunda kuşku bulunmadığından hükümlünün eyleminin TCY'nın 87/4. maddesi kapsamında değerlendirme olanağı yoktur.

Olayda hükümlü, dikkat ve özen yükümlülüğüne uymayarak iradi bir hareketiyle öleni göğsünden itmiş, ancak gerçekleşen sonucu yani ölümü öngörememiştir. Diğer bir anlatımla, hükümlünün kastı, kasten yaralamaya ilişkin olup meydana gelen ağır sonuç olan “ölümüne” yönelik değildir. Beton zeminde bulunan bir kişinin sert bir şekilde itilmesi sonucu yere sırt üstü

IV. Amaç veya Saik

Bazı suç tanımlarında, suçun unsurlarına ilişkin *kastın yanı sıra*, failin belli bir *amaç* doğrultusunda veya belli bir *saikle* hareket etmesi, bir *manevi unsur* olarak aranmaktadır.

Amaç veya saik, *kasttan önce gelen, kastı hazırlayan bir düşüncedir*³⁹³. Kanunî tarifte gerek suçun temel şekli gerek nitelikli şekli açısından bir unsur olarak kabul edilmiş olan amaç, Türk hukuk literatüründe Fransız hukukunun etkisiyle “*özel kast*” olarak ifade edilmiştir³⁹⁴. Yeni TCK’nın sisteminde, amaç veya saik, kastla özdeş veya kastın bir türü değildir. Bu bakımdan, artık “genel kast” – “özel kast” ayrımı terkedilmiştir³⁹⁵.

Amaç veya saik, bazı suçlar açısından, *suçun temel şekline ilişkin bir unsur* teşkil etmektedir.

Örneğin, “*Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt*” kurmak veya yönetmek (m. 220, f. 1; ayrıca bkz. m. 78, f. 1; m. 314, f. 1); insanlığa karşı suçlar açısından, belli fiillerin “*siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle*” (m. 77, f. 1) işlenmesi; göçmen kaçakçılığı suçu açısından, “*maddi menfaat elde etmek maksadı*”nın (m. 79, f. 1) güdülmesi; hırsızlık suçu açısından, “*yarar sağlamak maksadı*”yla hareket edilmesi (m. 141, f. 1); tefecilik suçu açısından, “*kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para*” verilmesi (m. 241); rüşvet suçu açısından, bir kamu görevlisinin, “*görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için*” kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması (m. 252, f. 1, 2); görevi yaptırmamak için direnme suçu açısından, “*kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit*” kullanılması (m. 265, f. 1); suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu açısından, “*gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacı*”yla hareket edilmesi (m. 281, f. 1); suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu açısından, bu değerlerin “*gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak*

düşerek ölebileceği objektif olarak öngörülebilir bir sonuç olmasına karşın hükümlü bunu öngörememiştir. O halde hükümlünün olayda meydana gelen ağır netice olan ölümden taksirle sorumlu tutulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.”

³⁹³ ARTUK, Emin: *Hürriyeti Tahdit Cürmü*, Halid Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul, 1996, sh. 48 vd. (66). Ancak, işaret etmek gerekir ki; bizim burada kullandığımız anlamda amaç kavramı karşılığı olarak Türk hukukunda *saik* kavramı kullanılmaktadır (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 933, 934; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 311).

³⁹⁴ ÖNDER, Genel Hükümler II. sh. 312.

³⁹⁵ *Yargıtay*, bazı suçlara ilişkin kanunî tarifte yer almamasına rağmen, failin işlediği fiil dolayısıyla cezalandırılabilmesi için “*özel kast*”la hareket etmesini aramaktadır: Mesela 765 s. TCK’nın görevi kötüye kullanma suçunu tanımlayan 240. maddesinde aranmadığı halde; *Yargıtay*’a göre, bu suçun oluşabilmesi için failin “*özel kast*”la hareket etmesi gerekmektedir: CGK, 2.3.1992, 9-38/61 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 2126); CGK, 17.2.1986, 4-431/48 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 2149); CGK, 19.3.1984, 4-396/99 (Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 2153).

maksadıyla” hareket edilmesi (m. 282, f. 1) hallerinde; amaç veya saik, ilgili suçun temel şekline ilişkin bir manevi unsur oluşturmaktadır.

Bazı suçlar bakımından amaç veya saik, suçun kanuni tarifinde *suçun nitelikli şekline ilişkin bir unsur* olarak belirtilmiştir.

Örneğin, kasten öldürme suçunun, “*bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla*” veya “*kan gütme saikiyle*” ya da “*töre saikiyle*” (m. 82, bent h, i, j); kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun, “*cinsel amaçla*” (m. 109, f. 5); hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarının, “*bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla*” (m. 144, bent b; m. 150, f. 1; m. 159); mala zarar verme suçunun, “*sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak*” (m. 152, f. 1, bent g); belgede sahtecilik suçunun, “*bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla*” (m. 211) işlenmesi hallerinde; amaç veya saik, faile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren bir nitelikli unsur oluşturmaktadır.

Bazı suçların kanunî tarifinde unsur olarak yer verilen amaç, bir başka fiilin işlenmesine yönelik olabilir. Meselâ rüşvet, bir kamu görevlisinin “*görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için*” kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir menfaat temin etmesidir (m. 252, f. 1, 2). Bu suç, haksız menfaatin kamu görevlisi tarafından temin edildiği anda tamamlanmış olur. Ancak, haksız menfaatin temini ile güdülen amaç bilahare gerçekleştirilebilir. Amacı oluşturan fiilin gerçekleşmesi, rüşvet suçunun oluşması açısından gerekli değildir. Keza, bir insanın diğer bir suçu işlemek için öldürülmesi halinde; oluşan kasten öldürme suçunun bu nitelikli şekli açısından, amaçlanan suçun işlenmesi gerekmez. Burada önemli olan, öldürme fiilinin belli bir amaçla işlenmesidir.

V. Kabahatlerde Manevi Unsur

5327 s. Kabahatler Kanununun “*Kast veya taksir*” başlıklı 9. maddesine göre; “*Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir.*”

Madde **gerekçesinde** ise, şu açıklamalar yer almaktadır³⁹⁶:

“Suçlar kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Ancak, kanunda açıkça belirtilmiş olması halinde, taksirle işlenen fiil de istisna olarak suç oluşturabilir.

Buna karşılık, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahat türünden haksızlıklar kural olarak hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Ancak, sadece kasten veya taksirle işlenebilen fiilin kabahat oluşturabileceği konusunda kanunda hüküm bulunabilir.

³⁹⁶ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840.

*Fakat, Tasarının sisteminde, kabahatler açısından da idari ceza sorumluluğunun kabulü yani idari para cezasına karar verilebilmesi için, **fiili işleyen gerçek kişinin en azından taksire dayalı kusurunun varlığı gerekir. Başka bir deyişle, kabahatler bakımından objektif sorumluluk kabul edilmemiştir.***

Halbuki, 765 sayılı (mülga) TCK'nın sistemine göre, failin cezalandırılabilmesi için, kabahat teşkil eden fiilin gerçekleşmiş olması yeterli sayılmıştı. Kabahat türünden bir suçun işlenmesi açısından failin kasten mi yoksa taksirle mi hareket ettiğinin araştırılmasına gerek yoktu (765 s. TCK, m. 45, f. 2). Objektif sorumluluk rejiminin benimsendiği 19'uncu yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir ürünü olan bu düzenleme doğru değildi. Aslında bu düzenleme, kabahat türünden bir suç işleyen kişi aleyhine olan bir sonuç ortaya çıkarmaktaydı. Şöyle ki, örneğin bir başkasının malvarlığına taksirle zarar verilmiş olması durumunda kişi mala zarar verme suçundan dolayı cezalandırılmayacaktır. Çünkü, bu suç ancak kasten işlenebilir (5237 s. TCK, m. 151; 765 s. TCK, m. 516). Buna karşılık, kamu makamlarından gerekli izin alınmaksızın başkasına ait binanın duvarlarına afiş yapıştırmak, yazı yazmak gibi fiiller dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için kastının sabit olması gerekmekteydi (765 s. TCK, m. 536).

§16. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru³⁹⁷

I. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı

Bir haksızlık olarak tezahür eden fiilin bir vasfı, hukuka aykırı olmasıdır. Hukuka aykırılık, işlenen fiilin hukuk düzenince tecviz edilmediğinin, mübah sayılmadığının bir ifadesidir³⁹⁸. Hukuka aykırılığın muhtevasını *davranış normları*³⁹⁹ tayin eder.

Kanun koyucu, bir hukuki düzenleme yaparken, pozitif hukuka takaddüm eden, öngelen davranış normlarını esas almalıdır. Bu itibarla, kanun koyucu hukuk kuralı yaratmaz; aksine onları davranış normlarından çıkararak pozitif hukuk metni haline getirir. Pozitif hukuk metinleri meşruluğunu, davranış normlarına uygunluğundan almaktadır⁴⁰⁰.

Bir fiilin hukuka aykırı olması, bunun bütün hukuk sistemine aykırı olmasını ifade etmektedir⁴⁰¹. Hukukun didaktik amaçlı olarak ve uygulamada işbölümü kolaylığı sağlaması itibarıyla çeşitli disiplinlere ayrılması, bu disiplinler arasında hukuka uygunluk veya aykırılık açısından farklı ölçütlerin olduğu anlamına gelmemektedir. Bir davranış, örneğin medeni hukukta olduğu gibi, ceza hukukunda da hukuka uygundur veya aykırıdır. Bu bakımdan, bir davranış, örneğin medeni hukukta hukuka aykırı ve fakat, ceza hukukunda hukuka uygun olarak nitelendirilemez. Keza, bir davranışın sadece bir hukuk disiplinine, örneğin medeni hukuka veya ceza hukukuna aykırılığından söz edilemez⁴⁰². Hukuk disiplinlerinde hukuka aykırı fiil dolayısıyla farklı sorumluluk ve yaptırım rejimi

³⁹⁷ Katoğlu, hukuka aykırılığın, suçun bir unsuru olmadığı görüşündedir. Ancak, yazar, suçun yapısına ilişkin izahlar çerçevesinde hukuka aykırılığın hangi bağlamda ele alınması gerektiği hususunda herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır (KATOĞLU, Hukuka Aykırılık, sh. 147, 160).

³⁹⁸ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 665; KUNTER, Kanunî Unsurlar, sh. 111 vd.; ALACAKAP-TAN, Suçun Unsurları, sh. 81; ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 165.

³⁹⁹ Bu kavramın karşılığı olarak “uygarlık kuralları”, “uygarlık normları”, “kültür normları” gibi ifadeler kullanılmaktadır (KUNTER, Suçun Maddi Unsurları, sh. 86; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 665, dn. 5; EREM, Genel Hükümler[8], sh. 35).

⁴⁰⁰ EREM, Genel Hükümler(8), sh. 35. Bu itibarla, “ümanist doktrin, sadece kanun koyucunun isteği ile bir fiilin suç sayılamıyacağı, bir fiilin ne zaman suç sayılabileceğini tayin edecek ölçülere ihtiyaç olduğu kanısında”dır (EREM, Genel Hükümler[8], sh. 36). Bir başka ifadeyle; “hukuka aykırılı(k,) münhasıran maddi (muhtevaya sahiptir) ve bu maddi muhtevayı *insanlık kuralları* tayin eder”r (EREM, Genel Hükümler[8], sh. 37, 38). Hukuka aykırılık, bütün hukuki nizam ile fiil arasındaki münasebetin ifadesidir (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 85/86, 98/99, 111 vd; aynı mealde TOROSLU, Ceza Hukuku, sh. 46). Ancak, Kunter, “hukuka aykırılığın ancak şeklen bahis mevzuu olabileceği fikrin”dedir (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 137 vd.).

⁴⁰¹ KATOĞLU, Hukuka Aykırılık, sh. 23, 24, 149, 155; KOCA, Mahmut: *YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri*, in: Ceza Hukuku Dergisi, yıl 1, sayı 1, Ekim 2006, sh. 115, 116.

⁴⁰² İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 101.

benimsenmiş olması, hukuk disiplinleri arasında hukuka aykırılık ölçütleri ve hukuka uygunluk sebepleri bakımından farklılıklar olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, mesela medeni hukuk alanında hukuka aykırılık teşkil eden bir fiil, ceza hukukunun müdahalesini gerektirmeyebilir. Bu durum, söz konusu fiilin ceza hukuku bakımından hukuka uygun olduğu anlamına gelmez. Belirli bir fiil dolayısıyla ceza hukuku alanında yaptırım öngörülmemiş olmasından, bu fiilin hukuka uygun olduğu sonucu çıkarılamaz.

Aynı ilişki hukukla ahlâk arasında da söz konusudur. Gerek ahlâkın gerek hukukun müşterek bir kaynağı mevcuttur⁴⁰³, bu da, davranış normlarıdır. Ahlâk ve hukuk kuralları müşterek bir zemine sahip bulunmaktadır⁴⁰⁴. Bu itibarla, hukuki olan bir davranış, aynı zamanda ahlâkîdir; ahlâka aykırı bir davranış hiçbir zaman hukuki koruma altına alınamaz⁴⁰⁵.

⁴⁰³ KAUFMANN, Arthur: *Recht und Sittlichkeit*, Tübingen, 1964, sh. 34. Aksi fikir için bkz. DÖNMEZER, Sulhi: *Cezaî Mesuliyetin Esası*, İstanbul, 1949, sh. 25; DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku*, cilt I, 9. bası, İstanbul, 1985, no. 225.

Alacakaptan, ahlâk ile hukukun alanlarının bugün “birbirinden kesin olarak ayrılmış olduğu” iddiasında bulunmaktadır (ALACAKAPTAN, Uğur: *Suçun Unsurları*, Ankara, 1970, sh. 11/12).

Önder, bu konuda çelişkili ifade kullanmaktadır: “Hukuk ve ahlâk kuralları birbirini kesen iki daireye benzetilebilir. Hukuk kuralları, ahlâk kurallarının hepsini bünyesine almış olduğu düşünülemez. Ahlâk kurallarının birçoğu hem bir ahlâk kuralıdır hem de hukuk tarafından bünyesine alınmıştır. Hukuk ve ahlâk kurallarının iki daire gibi birbirini kestiği ve her iki kuralın birleştiği halin dışında da hukuk kurallarının ahlâk kuralları ile ilişkisinde asgari ahlâk kurallarının varlığı gözlemlenir. Ancak, hukuk düzeni ile ahlâk düzeninin temellerinin farklı olması sonucu, hukuk düzeni her ahlâk kuralını bünyesine alıp bunları hukuk düzeninde geçerli kurallar haline getiremez.” (ÖNDER, Ayhan: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, Cilt I, İstanbul, 1991, sh. 2 vd.).

İçel/Donay’ın bu konuda ileri sürdüğü görüş, sonuçta doğrudur: “Ahlâk normları ile ceza hukuku arasındaki ilişki inkar edilemez. Şöyle ki, toplumun ahlâk normlarına tamamen aykırı ceza hukuku kuralları konulamayacağı gibi, yüksek ahlâkî değerlere aykırı davranışları da ceza hukuku görmezlikten gelemez. Başka bir anlatımla, ceza hukuku ve ahlâk içiçe iki daire gibi olup, ahlâka ilişkin daire ceza hukuku dairesini de içermektedir.” (İÇEL, Kayıhan/DONAY Süheyl: *Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I*, 2. bası, İstanbul 1993, sh. 18).

Toroslu’nun şu fikirlerine katılmıyoruz: “Ceza hukukunun önemli bir kesimi (politik suçlar, kabahatler gibi) ahlâk ile hiç ilgisi olmayan veya çok az ilgisi bulunan politik zorunluluk veya pratik elverişlilik ölçütlerinden esinlenmektedir.” (TOROSLU, Ceza Hukuku[4], sh. 17).

⁴⁰⁴ “Tabii hukukun yasakları, aynı zamanda ahlâkın da yasaklarıdır” (HATEMÎ, Hüseyin: *Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları*, İstanbul, 1976, sh. 33, dn. 7).

⁴⁰⁵ HATEMÎ, Hukuka ve Ahlâka Aykırılık, sh. 33. Erem, hukukla ahlâk arasındaki ilişkiyle alakalı olarak tamamen katıldığımız şu tespitlerde bulunmaktadır: “Ahlâkça kötü bir hareketin hiçbir zarar doğurmadığına misal bulunamaz. Ahlâkça kötülükleri arttığı bir toplumda sosyal düzen kaybolur, budan sonra hürriyette bahsedilemez” (EREM, Faruk: *Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, 8. bası, Ankara, sh. 10/11); “eğer bu gün ceza hukuku ile ahlâk ayrı gibi görünüyorsa; bu, hukuk tekniğinin henüz başarıya tam anlamı ile ulaşamadığımızdandır. Halen öyle suçlar vardır ki, suç sayılmalarında ahlâkça zaruret yoktur; buna mukabil, ahlâkça suç olan pek çok hareketlerin henüz kanunca suç sayılmamış olması, izahsız kalmaktadır”. Bu itibarla, “hukuk tekniği, ahlâkın gereği gibi uygulaması çabası” olarak anlaşılmalıdır (EREM, Genel Hükümler[8], sh. 11, ayrıca, 58/59).

Bu müşterek zemine karşılık; ahlâkla hukuk arasında bir farklılık mevcuttur. Davranış normlarına aykırı her davranış, ahlâka aykırılık arzeder ve dolayısıyla, “ahlâkî” sorumluluğu gerektirir. Hukukun alanı ise, bu davranış normlarına aykırılığın hukuk toplumu, bu toplumda hakim olan düzeni bozucu bir boyuta ulaştığı anda başlamaktadır. Örneğin soyut yalan, doğru sözlülüğü emreden davranış normlarına ve dolayısıyla, ahlâka aykırı bir davranıştır. Ancak, yalanın bir başkasının hukukunu etkileyici bir sonuç icra edebileceği durumlarda, hukukun meseleye müdahale alanı başlamaktadır. Yani, çeşitli yalan beyan tarzları itibarıyla, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, hile, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi haksızlıkların gerçekleşmesi halinde, hukukun müdahale edebileceği bir norma aykırılık mevcut olacaktır⁴⁰⁶.

Demek ki, hukukla ahlâk arasında sıkı bir münasebet mevcuttur⁴⁰⁷. Pozitif hukuk, ahlâkî yükümlülüklerin yerine getirilmesine insanı *meçbur* eden bir araç olarak değil; bunların yerine getirilmesini insana *mümkün* kılan bir araç olarak anlaşılacaktır. Böylece, hukukun amacı ahlâkî bir temele oturtulmuş olmaktadır: Hukuk, insan şahsiyetinin serbestçe tekâmülünü mümkün kılacak, bunun şartlarını teminat altına alacaktır⁴⁰⁸. Netice olarak, hukukla ahlâk arasında hiçbir zaman bir çelişkinin mevcudiyetinden bahsedilemez^{409, 410}.

Aral, bir taraftan “ahlâk, bireyin kendi vicdanının ürünüdür. Ahlâk alanında bir iç kanun koymadan ... söz edilir. Ahlâk normlarının, onları koyan bireyin vicdan ve zihniyetinden başka bir kanun koyucusu yoktur” derken (ARAL, Vecdi: *Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine*, 6. bası, İstanbul, 1991, sh. 74); diğer taraftan ahlâkın “*birey üstü objektif değerler düzenine ilişkin*” olduğundan bahsetmektedir (aynı sahife). Ahlâk normlarının kaynağı konusunda bir çelişkiyi ifade eden bu açıklamaların yanı sıra; *Aral*, hukukla ahlâk arasındaki farkı ortaya koymaya çalışırken, “kanuna (hukuka) uygunluk (legalite) ile ahlâka uygunluğun (moralite’nin) birbirinden ayrı olduğu sonucu”na varmaktadır. *Aral*’a göre; “hukuka uygun bulunan bir fiilin zorunlu olarak ahlâka da uygun bulunması gerekmez” (sh. 72). Keza, *Aral*, “hukukta sorumlu olunan makamın dışta, ahlâka ise içte bulun”duğundan bahsetmektedir (sh. 75). “Hukukun idesi ve idealinin adalet olmasına karşılık ahlâkın amacı(nın), ideali(nin) iyi’yi (hayrı) gerçekleştirmek” olduğunu söyleyen *Aral*’a göre; “adalet ile iyi arasındaki ayırım da, adaletin toplumsal bir değer olmasında, onun doğru, herkesi hoşnut eden, yetkin bir toplumsal düzeni deyimlemesinde, buna karşılık, ahlâkın ideali olan iyi’nin ise, tek tek insanla, onun yetkinliği ile ilgili bir değer oluşunda gösterilir” (sh. 77). Fakat, yazar, aynı eserde doğru olarak şu tespitlerde bulunmaktadır: “... adalet de iyidir, iyi bir şeydir ve bu yüzden aynı zamanda ahlâkî bir kavramdır. ... *adaletin gerektirdiği toplumsal yaşam*, kişisel yaşamın bir yanısıdır ve bu yan, *temelinde ahlâk normlarına tabidir*” (sh. 81).

⁴⁰⁶ Bu hususta bkz. ERMAN, Sahir: *Sahtekârlık Suçları*, 4. bası, İstanbul, 1981, no. 2 vd.

⁴⁰⁷ Arth. KAUFMANN, *Recht und Sittlichkeit*, 17. Bu ilişki, aynı merkeze sahip ve fakat çapları birbirinden farklı olan iki daireye benzetilmektedir. Bunlardan çapı büyük olan ahlâkî, küçük olan ise hukuku ifade etmektedir.

⁴⁰⁸ Arth. KAUFMANN, *Recht und Sittlichkeit*, 17/18.

⁴⁰⁹ Arth. KAUFMANN, *Recht und Sittlichkeit*, 28 vd., 31 vd. Hukukla ahlâk ilişkisi açısından ayrıca bkz. HATEMİ, *Hukuka ve Ahlâka Aykırılık*, sh. 34, dn. 8.

⁴¹⁰ Ahlâkın ölçütlerinin, yaşamın kültür ortamına göre, bir başka ifadeyle, yere ve zamana göre değişkenlik arzedeceği hususundaki görüş (DÖNMEZER, Sulhi: *Ceza Hukuku, Özel Kısım, Genel Adab ve Aile Düzenine Karşı Cürümler*, 5. bası, İstanbul, 1983, no. 183), kanaatimizce, isabetli değildir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, örf ve adetler bir fiilin hukuka uygun kabul edilmesinin gerekçesini oluşturmazlar^{411, 412}.

⁴¹¹ ÖZGENÇ, İzzet: *Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar*, Ankara, 2002, sh. 141 vd.; aynı yazar, *Zimmet Suçu*, Ankara, 2009, sh. 24 vd.

⁴¹² **OLAY:** Düğün günü seyir halindeki “gelin arabası”nın yolu gençler A, B ve C tarafından kesilerek “bahşiş” istenir. Araç içinden uzatılan zarf içindeki para miktarı gençler tarafından yetersiz görülür. Bunun üzerine gelin arabasında bulunan D ile gençler arasında tartışma çıkar. Bu nedenle düğün konvoyu bir süre yolda tutulur. D, karakola başvurarak, gençler A, B ve C hakkında yol kestiklerinden bahisle suç duyurusunda bulunur.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Örf ve adetler, hukuka uygunluk sebebi oluşturmazlar. Örf ve adetlere dayalı olarak gerçekleştirilen fiiller, toplumda hoşgörüyle, müsamahayla, toleransla karşılanabilirler. Bir davranışın toplumda hoşgörüyle karşılanması bunun hukuka uygun olduğunu kabule gerekçe teşkil etmez.

Hoşgörü (müsamaha, tolerans), esasen bir tasvip edilmezlik ifade etmektedir. Başkasına ait bir davranışın hoş görülmesi, bu davranışla ilgili bir tasvipsizlik yargısına işaret etmektedir. Daha açık bir ifadeyle, kişi kendi telakkilerine göre tasvip etmediği, doğru bulmadığı bir davranışın başkası tarafından gerçekleştirilmesini hoş görmektedir; bu davranışı müsamaha ile, toleransla karşılamaktadır.

Toplumda egemen olandan farklı bir inanç, düşünce kişiler tarafından hoşgörüyle karşılanabilir. Başlı başına hoşgörü, bir hukuka uygunluk sebebi oluşturmaz. Bir davranışın salt hoş görülmesi, bunun hukuka uygun olduğunu kabulün gerekçesi olamaz. Hoşgörüyle karşılanmasa bile, bir düşüncenin, inancın açıklanması, bir hak ve özgürlük kapsamında değerlendirilmelidir. Farklı inanç ve düşüncelerin açıklanmasının hukuka uygunluk temelini, hoşgörü değil, milletlerarası sözleşmelerle ve anayasalarla güvence altına alınmış olan bir hak ve özgürlük oluşturmaktadır.

Düğünlerde yol kesilerek “bahşiş” talep edilmesi, örf ve adet gereği olarak toplumda hoşgörüyle karşılanmaktadır. Ancak, bu hoşgörü, söz konusu fiilin hukuka uygun kabul edilmesini sağlamaz. Hoşgörü ile karşılanan fiil ve davranışlar, kişilerin tahammül sınırını zorlamadığı sürece, hukuki yaptırım uygulanmasını gerektirmez. Bir fiil ve davranışın hoşgörüyle karşılanması halinde, hukuki yaptırım uygulanmasını gerektirecek boyutta bir haksızlığın varlığından söz edilemez.

Asker uğurlaması sırasında cadde ve sokaklarda bazı trafik kurallarını ihlal eder tarzda gece geç saatlere kadar dolaşılması suretiyle kişilerin huzur ve sükunu bozulmaktadır. Ancak, buna rağmen asker uğurlayan gençler hakkında herhangi bir hukuki yaptırım uygulanmamaktadır. Trafik düzenini, toplumun huzur ve sükununu bozan bu davranışlar, hoşgörüyle karşılanmaktadır. Ancak bu hoşgörünün sınırı bulunmaktadır. Bu kabil davranışlar, toplumun tahammül sınırını zorlamadıkları sürece hoşgörüyle karşılanmaktadır. Ancak, asker uğurlaması sırasında trafik kurallarının ihlali suretiyle araç kullanılarak başkasının yaralanmasına veya aracının zarar görmesine sebebiyet verilmiş ise, artık hoşgörüyle karşılanacak bir fiilden söz edilemez.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, “gelin arabası”nın önü kesilerek “bahşiş” istenmesi, bir gelecektir. Bu geleneğe dayalı olarak düğün konvoyunun trafikte bir süre alıkonulması, hoşgörüyle karşılanır. Ancak, bu hoşgörü, kişilere “yol kesme hakkı”nı bahsetmez ve “gelin arabası”ndakileri “bahşiş” adıyla bir “para verme borcu” altına sokmaz. Bu nedenledir ki, yol kesenlerin beklentilerine uygun miktarda para verilmemesi üzerine çıkan tartışmada yol kesenlere karşı işlenen suç bağlamında haksız tahrik hükümleri uygulanabilecektir.

“Bahşiş” olarak verilen paranın yetersiz görülmesi ve istenen miktarda para verilmediği için geçişin engellenmesinde ısrar edilmesi halinde, artık tahammül sınırı aşılmış olmaktadır. Tahammül sınırının aşıldığı durumlarda, işlenen fiilin mahiyetine göre ceza yaptırımına hükmetmek gerekir. Örneğin istenen miktarda paranın verilmemesi nedeniyle geçişi engellemek

Suç teşkil eden “*haksızlık*”, diğer hukuk disiplinlerindeki haksızlıklardan yapı, nitelik veya bir olay olarak farklı değildir. Her suç hukuka aykırı bir fiilin varlığını ifade etmekle birlikte, her hukuka aykırı fiil bir suçun varlığını ifade etmemektedir⁴¹³.

Hukuka aykırılık ve *haksızlık* kavramlarını da birbirinden ayırmak ve birbirleriyle karıştırmamak gerekir. Hukuka aykırılık, suç oluştursun veya oluşturmamasın, fiilin bir *vasfıdır*. Fakat, haksızlık ise, hukuka aykırı olan fiilin bizzatî kendisini ifade etmektedir⁴¹⁴.

Bir fiil ya hukuka aykırıdır veya değildir. Bir fiil hukuka aykırı olduktan sonra, bu aykırılığın azlığından veya çokluğundan söz edilemez. Bu itibarla, hukuka aykırılık, suç teşkil eden fiilin bir sıfatıdır. Ancak, hukuka aykırı olan fiillerin ifade ettikleri haksızlık muhtevaları birbirlerine nazaran farklılık arz edebilir⁴¹⁵.

Suç tanımlarının koruduğu hukuki değer ile suçun maddi ve manevi unsurları, haksızlık içeriğinin belirlenmesinde ölçüt olarak alınmaktadır. Şöyle ki, hayata karşı fiiller ile vücut bütünlüğüne karşı veya malvarlığına karşı fiillerin ifade ettiği haksızlık içerikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık dolayısıyla ki, ceza kanunlarında her bir hukuki değer ihlali mahiyeti taşıyan fiiller, ayrı suç kategorileri olarak tanımlanmıştır.

Keza, bir suçun konusu itibarıyla da haksızlık içeriği farklılık arz edebilir. Örneğin çalınan eşyanın değerinin azlığı veya fazlalığı, mağdur veya toplum bakımından önemi, hırsızlık suçunun haksızlık muhtevasının farklılaşmasını sağlar.

için yola çekilen aracın motoru durdurularak kontak anahtarıyla birlikte olay mahallinden ayrılması halinde, TCK’nın 109. maddesinde tanımlanan “**Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma**” suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Hatta daha da ileri gidilerek, istenilen miktarda para verilmesini sağlamak için, yol kesen kişiler tarafından “gelin arabası”ndaki kişilerin tehdit edilmesi veya bu kişilere cebir uygulanması halinde, TCK’nın 148 ve 149. maddelerinde tanımlanan “**Yağma**” suçunun tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış olduğunu kabul etmek gerekir.

⁴¹³ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 103; AKBULUT, Genel Hükümler, 5. bası, sh. 221.

Ozansü, hukuka aykırılık kavramından ayrı olarak haksızlık kavramını kullanmakla birlikte, oluşturmaya çalıştığı kendine özgü hukuki düşünce modelinde “*medeni hukuk haksızlığı*” ile “*ceza hukuku haksızlığı*” arasında “*nitelik farkı*” olduğunu ileri sürmektedir (OZANSÜ, Kastan Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 25 vd.).

⁴¹⁴ Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Yargıtay Dergisi, 19(1993), sayı 4, sh. 490; aynı yazar: *Uygulamalı Ceza Hukuku, Çözümü Örnek Olaylar ve Karar Tahlilleri*, 2. Bası, İstanbul 1998, sh. 28, 36, 39, 126, 144 vd.; (İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 94/95); YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 249; KOCA, Ceza Hukuku Dergisi, Ekim 2006, sh. 116 vd.; GÖKTÜRK, Neslihan: *Haksızlık Yanılgısının Ceza Sorumluluğuna Etkisi*, Ankara, Aralık 2016, sh. 21; KILIÇ, Ali Şahin: *Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara 2020, sh. 28.

⁴¹⁵ Ünver, bu bağlamda “haksızlık içeriğinin az veya çok oluşundan söz etmektedir (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 468).

Belli bir suç işleme yönelik fiilin icra tarzı, suçun işlenmesinde kullanılan vasıta, bu suçun haksızlık muhtevasının değişkenlik arz etmesini sağlar. Yumrukla işlenmiş kasten yaralama suçunun ifade ettiği haksızlık içeriği, bıçakla veya sair bir silahla işlenmiş yaralama suçunun ifade ettiği haksızlık içeriği ile aynı değildir.

Keza, ihmali hareketle işlenen suçun ifade ettiği haksızlık içeriği, icrai hareketle işlenen suçun ifade ettiği haksızlık içeriğine nazaran daha az olabilir. Bu nedendir ki, kasten öldürme suçunun ihmali hareketle işlenmesi halinde, failin cezasında indirim yapma konusunda hakime takdir yetkisi tanınmıştır (TCK, m. 83).

Fiilin hukuka aykırılık özelliğinin kusurluluk gibi bir derecelendirmeye tabi tutulup tutulmayacağı tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmanın ana kaynağını, "hukuka aykırılık" kavramıyla "haksızlık" kavramının birbiriyle karıştırılması oluşturmaktadır. Halbuki hukuka aykırılık, fiilin bir özelliğini, karakterini, bir başka ifadeyle, hukuk düzeniyle fiil arasındaki uyumsuzluğu ifade etmektedir. Buna karşılık, haksızlık ise, nesnel bir şeye işaret etmektedir; haksızlık, hukuka aykırı fiilin bizzat kendisini ifade etmektedir.

Hukuka aykırı oluş, değerlendirmeye tabi tutulan bir fiilin hukukun icaplarına uygun düşmediğinin tespitinden başka bir şey ifade etmemektedir. Bu anlamda "hukuka aykırılık"ın bir derecelendirmeye tabi tutulması kabil değildir. Bu itibarla, meselâ basit bir yaralama fiili, ağır bir yaralamaya nazaran "daha az" hukuka aykırıdır diyemeyiz⁴¹⁶.

Fakat, şu muhakkaktır ki, yaralama örneğimize sadık kalırsak, bu farklı sonuçlar doğuran davranış biçimleri arasında, haksızlık muhtevası itibarıyla bir farklılık mevcuttur. Bu nedenle, her iki yaralama fiilinden birisi diğerine nazaran daha az veya daha fazla bir haksızlık ifade edebilir. Sonuç itibarıyla, bir fiil, ya hukuka uygun, ya da aykırıdır. Hukuka aykırı olan bir fiilin ifade ettiği haksızlık ise, niceliksel, kemiyet itibarıyla bir derecelendirmeye tabi tutulabilecektir⁴¹⁷.

⁴¹⁶ Aynı yönde değerlendirmeler için bkz. KEÇELİOĞLU, Elvan: *Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Sebeplerle Hukuka Uygunluk Sebepleri Arasındaki Ayrımın TCK'nın Uygulanması Bakımından Pratik Sonuçları*, in: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 87, Mart – Nisan 2010, sh. 302. Ancak, Katoğlu, hukuka aykırılığın derecelendirilebilir olduğu görüşünün etkisinde kalarak, hukuki değer ihlalinin derecelendirilebilir olduğundan ve bu bağlamda "hukuka aykırı fiilin içeriği(nden), yani ihlal ediciliği"nden söz etmektedir (KATOĞLU, Hukuka Aykırılık, sh. 70/71, 157).

⁴¹⁷ Bu itibarla, Yargıtay'ın şu kararındaki görüşe iştirak etmiyoruz:

«... Resmen ve serbest piyasada alım gücü bulunmayan 31 TL. değerindeki madeni Irak Dinarını çaldığını söyleyen sanığın fiilinin, ihlâl edilen menfaat ve dolayısıyla nicelik açısından malvarlığında bir zarar doğurmadığı ve bu nedenle gündüzün bina içinde hırsızlığa eksik kalışma aşamasında kaldığı ... gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması» hukuka aykırıdır: 6. CD, 21.3.1990, 1225/2265 (YKD Eylül 1990, sh. 1407). Benzer bir karar için ayrıca bkz. CGK, 25.6.1990, 5-157/200 (YKD, Eylül 1990, sh. 1381 vd. [1383]).

Bir fiilin cezalandırılmayı gerektiren bir nitelik taşıması, genel ve soyut bir değerlendirilmeye dayanır. Örneğin bir başkasının malını sahibinin rızası olmadan almak, hırsızlık olarak **cezalandırılmayı gerektiren bir fiildir**. Buna karşılık, fiil esasen cezalandırılmayı gerektirmekle birlikte, somut olayda bir başkasına ait olan ve sahibinin rızası olmadan alınan malın değerinin azlığı nedeniyle, failin cezalandırılması yoluna gidilmeyebilir. Aynı durum, malvarlığına zarar verme suçu bakımından da söz konusu olabilir. Keza, bir insana onurunu, şeref ve saygınlığını rencide edecek mahiyette yakıştırmada bulunmak, hakaret suçunu oluşturur. Ancak, hakaret edilen kişinin siyasi bir kimlik sahibi olması, üstlendiği idari görev nedeniyle eleştirilere daha açık olması, kendisine yöneltilen ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunması durumunda, muhatap olduğu söz veya ifade hakaret mahiyeti taşısa bile, siyasi kimliği veya üstlendiği idari görevin gereği olarak eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğu için, bu görevle bağlantılı olarak maruz kaldığı ithamlar hakareti tazammun etse bile, bu ithamlarda bulunan kişinin cezalandırılması yoluna gidilmemektedir. Bu durumda **cezalandırma ihtiyacından söz edilemez**⁴¹⁸. Gerçi bu durum eleştiri hakkı çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Belirtmek gerekir ki eleştiri hakkı, muhatap kim olursa olsun, bir başkasına hakaret etme hakkını kimseye vermez. **Sarf edilen söz veya kullanılan ifadenin mahiyet itibarıyla hakareti tazammun edip etmediği, muhatap alınan kişinin kimliğine veya ifa ettiği göreve göre belirlenemez. Aksine, hakareti tazammun eden yönleri bulunsu bile, kamusal bir faaliyetle ilgili, ifa edilen görevle bağlantılı eleştiri kapsamında sarf edilen, kullanılan söz veya ifadeler dolayısıyla kişiler cezalandırılmaz.** Başka bir deyişle, **muhatap alınan kişinin kimliği, hakaret içeren yönleri bulunsu bile, ifa ettiği görevle bağlantılı olarak kendisine yöneltilen eleştiri kapsamında sarf edilen, kullanılan söz veya ifadeler dolayısıyla cezalandırmaya engel teşkil eder.**

Bizatihi haksızlık teşkil eden fiilin hukuka aykırılık vasfını somut olayda ortadan kaldıran bir durum söz konusu olmamalıdır. Bir fiilin kanunda muayyen suç tanımlarından birine uygun olması, bu fiilin mutlaka hukuka aykırı olduğu so-

Karara konu teşkil eden olayda fail çok az değerdeki Irak Dinarını çalmıştır. Fail, hatta "değersiz" denebilecek bir şeyi malikinin hakimiyet alanından çıkarıp, kendi hakimiyet alanına sokmuştur. Bu itibarla, olayda teşebbüsten bahsetmek mümkün değildir. Hırsızlık suçu tamamlanmıştır. Ancak, hırsızlık konusu şeyin değerinin "değersiz" denecek kadar çok az olması, işlenen fiilin haksızlık muhtevasına ilişkin bir husustur. Fiilin ifade ettiği haksızlığın çok düşük olması halinde, faile ceza vermektен sarfinazar dahi edilebilmelidir.

Nitekim, yeni TCK'nda bu yönde hükümlere yer verilmiştir: Örneğin, "*Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermektен de vazgeçilebilir.*" (m. 145).

⁴¹⁸ Alman hukukundaki Strafwürdigkeit – Strafbedürftigkeit kavramları ve bunlar arasındaki anlam farkı için bkz. KILIÇ, Ali Şahin: *Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık (Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru)*, Ankara, 2023, sh. 89 vd.

nucunu doğurmaz. Ancak, bu uygunluk, işlenen fiilin aynı zamanda hukuka aykırı olduğu hususunda bir *karine* teşkil etmektedir. Bir başka ifadeyle; işlenen fiilin kanunla muayyen suç tanımlarından birine uygun düşmesi halinde, bu fiilin hukuka aykırılığının ayrıca araştırılmasına gerek yoktur. Aksine, kanunla muayyen suç tanımlarından birine uygun düşen bu fiilin, buna rağmen, hukuka uygun olmasını gerektiren bir durumun mevcut olup olmadığının araştırılması gerekecektir. Şayet işlenen fiile ilişkin olarak bir hukuka uygunluk sebebinin mevcudiyeti sonucuna varılırsa, artık işlenen fiilin bir haksızlık teşkil ettiğinden bahsedilemez. Bu durumda her ne kadar kanunla muayyen bir suç tanımına uygun bir fiil işlenmişse de, bu fiilin hukuka aykırılığından bahsetmek mümkün olmayacaktır⁴¹⁹.

Klasik suç teorisinde fiilin haksızlık muhtevasının tayininde sadece netice esas alınmaktaydı. Bu nedenle; bir hukuka uygunluk sebebinden yararlanabilmek için, bu sebebin şartlarının objektif olarak mevcudiyeti yeterli görülmekteydi⁴²⁰.

⁴¹⁹ AKBULUT, Genel Hükümler 5. bası, sh. 230 vd. Kanuni tarife uygun olmasını, tipikliği, fiilin hukuka aykırı olduğunun, hukuka aykırılık oluşturduğunun “belirtisi” olarak nitelendirilmesi, her somut olay bakımından herhangi bir hukuka uygunluk sebebinin gerçekleşmiş olup olmadığının, her bir hukuka uygunluk sebebi bakımından tek tek araştırılmasını gerekli kılar. Bu kabul, yargılama faaliyetinin içinden çıkılmaz bir şekilde uzamasına neden olur. Bu nedenle, fiilin kanuni tarife uygunluğunu hukuka aykırılık bakımından bir *karine* olarak kabul etmek, daha gerçekçi bir yaklaşımdır.

⁴²⁰ OEHLER, Dietrich: *Das objektive Zweckmoment in der rechtswidrigen Handlung*, 1959, sh. 165 vd.; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 672; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 168 vd.; EREM, Faruk: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler*, cilt II, 12. bası, 1985, sh. 1 vd. Keza, Kunter’e göre, “hukuka uygunluk sebeplerinin objektif olarak mevcudiyetinin kâfi görülmesi, bu sebeplerin failin bilgisinden kaideten müstakil olduğunu göstermektedir” (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 151).

Müşterek yazarları arasında bulunduğum bir kitabın meslektaşım Ünver tarafından yazılan bir bölümünde de, aynı düşünce hakimdir: “Hukuka aykırılık, eylemin objektif bir değerlendirilmesidir ve eylem ile hukuk düzeni arasındaki bir çelişkiyi ifade eder. Eylemin hukuka aykırılığı değerlendirilirken, hem kanunî tip açısından tipik olup olmadığı hem de eylemin hukuka aykırılığını kaldıran ve hukukun herhangi bir alanından doğan bir hukuka uygunluk nedeninin mevcut olup olmadığı araştırılır. Hukuka aykırılığın fail açısından bir sorumluluk doğurabilmesi için onun iradesinin bunu kapsar nitelikte olup olmaması, bu değerlendirmenin dışında kalır.” (İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/ MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 99, ayrıca sh. 111). (Ayrıca bkz. 4. CD, 19.9.1990, 3748/4259 (YKD, Mayıs 1991, sh.782/783). Ancak, söz konusu kitapta yer alan “hukuka aykırılık ve yanılma” başlığı altında, bu kabulle bağdaşmayan açıklamalara yer verilmiştir:

“... eylemsel yanılma (fiili hata) durumlarında hukuka aykırılık etkilenir. Yani, kişi somut olayda koşulları gerçekleşmeyen hukuka uygunluk nedeninin oluştuğu kanısıyla hareket etmişse, yanılmanın esaslı olması halinde bundan yararlanır. Esaslı olmayan yanılmalarda ise hukuka aykırılık ortadan kalkmaz. ... Eylemsel yanılma esaslı olup olmamayı saptarken uygulanan kriteri şöyle belirtebiliriz: Fail yanılığa düşmeseydi eylem hukuka uygun sayılacak idiyse, hata esaslıdır. Buna karşılık failin yanılığa düştüğü koşullar failin zannettiği gibi gerçekleşseydi dahi ortada hukuka uygunluk nedeni bulunmayacak idi ise, bu takdirde yanılma esaslı değildir ve bu nedenle de eylemin hukuka aykırılığı devam eder.” (İÇEL/SOKULLU-

Buna karşılık, günümüz ceza hukuku anlayışına göre; kişi işlediği fiilin hukuka aykırılık teşkil ettiğinin bilincinde olmalıdır⁴²¹.

Yeni TCK'daki bazı suç tanımlarında örneğin “*hukuka aykırı olarak*”⁴²², “*hukuka aykırı başka bir davranışla*”⁴²³, “*hukuka aykırı diğer davranışlarla*”⁴²⁴, “*hukuka aykırı yolla*”⁴²⁵, “*hukuka aykırı yollarla*”⁴²⁶, kamu “*görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle*”⁴²⁷, kamu “*görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle*”⁴²⁸, kamu “*görevinin gereklerine aykırı olarak*”⁴²⁹, kamu “*görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle*”⁴³⁰, kamu “*görevinin gereklerini yapmakta ihmâl veya gecikme göstererek*”⁴³¹ gibi ifadelerle yer verilmiştir. Bu ifadelerle, ilgili suç tanımında yer alan fiilin hukuka aykırılığına özellikle işaret edilmiştir. Bu suretle, Kanun koyucu, failin, işlediği fiilin hukuka aykırı olduğunu bilmesini yani, işlediği fiilin hukuka aykırı olduğu hususunda *doğrudan kastla* hareket etmesini aramıştır. Başka bir deyişle, ilgili suç tanımında fiilin hukuka aykırılığına özellikle işaret edilmiş olan hallerde, bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir⁴³².

AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 2. bası, sh. 114). Yine belirtmek gerekir ki; bu bölüm altında yapılan açıklamaların bir kısmı, hukuka uygunluk nedenlerinde yanılma ile değil, hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasıyla ilgilidir.

Ancak, klasik suç teorisinin etkisindeki yazarlar da, kanundaki düzenleniş itibarıyla, belli hukuka uygunluk sebepleri açısından, kişinin hukuka uygunluk sebebinin varlığı bilinciyle hareket etmesi gerektiği fikrindedirler (ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 168 vd.). Buna göre, meselâ tıbbî müdahalelerde hukuka uygunluk sebebinden bahsedebilmek için, “doktorun tedavi amacı ile hareket” etmesi şarttır (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 729). Keza, iddia ve savunma dokunulmazlığına ilişkin olarak, “söz konusu hukuka uygunluk sebebinin varlığı için; isnatların, doğruluğuna inanılarak, yapılması lazımdır” (DÖNMEZER, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 13. bası, 1990, no. 264 bis.). *Kunter*’e göre, işlenen fiille alâkalı olarak bir hukuka uygunluk sebebinin mevcut olduğu hususundaki bilginin arandığı durumlarda, bu bilgi kasta dahil değildir (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 150/151). Fakat, *Kunter*, bu bilginin hangi kapsamda tetkik edilmesi gerektiği hususunda herhangi bir açıklamaya yer vermemiştir.

⁴²¹ ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 74; KOCA, Ceza Hukuku Dergisi, Ekim 2006, sh. 121 vd.; ÇINAR, Ön Kusurluluk, sh. 63 vd.

⁴²² Yeni TCK, m. 91 [f. 2], 109 [f. 1], 120, 124 [f. 1, 2, 3], 132 [f. 2], 135 [f. 1, 2], 136, 139, 209 [f. 2], 243 [f. 1], 260 [f. 1], 277.

⁴²³ Yeni TCK, m. 112, 113, 114 [f. 2], 115 [f. 2], 117 [f. 1], 118 [f. 2], 223 [f. 1, 3], 224, [f. 1].

⁴²⁴ Yeni TCK, m. 235 [f. 2, bent (c)].

⁴²⁵ Yeni TCK, m. 239 [f. 1].

⁴²⁶ Yeni TCK, m. 91, [f. 5].

⁴²⁷ Yeni TCK, m. 250 [f. 1].

⁴²⁸ Yeni TCK, m. 250 [f. 2].

⁴²⁹ Yeni TCK, m. 252 [f. 3].

⁴³⁰ Yeni TCK, m. 257 [f. 1].

⁴³¹ Yeni TCK, m. 257 [f. 2].

⁴³² “5237 sayılı kanunda bazı suç tanımlarında “*hukuka aykırı olarak*”, “*hukuka aykırı başka bir davranışla*”, “*hukuka aykırı diğer davranışlarla*”, “*hukuka aykırı yolla*”, “*hukuka aykırı yollarla*” gibi ifadelerle yer verilmiştir. Bu ifadelerin geçtiği suçlarda failin, işlediği fiilin hukuka

Hukuka aykırılığın ilgili suç tanımında özellikle vurgulandığı durumlarda; ceza sorumluluğu için failin, işlediği fiille ilgili olarak suçun maddi unsurlarının yanı sıra, bu fiilin hukuka aykırılığının da bilincinde olup olmadığının ayrıca araştırılması gerekir. Aksi takdirde, kastının varlığından söz edilemez^{433, 434}.

Suç tanımında normatif unsurlara yer verilmesi ile, suçun değerlendirilebilir unsurlarının varlığının kabulü ile hukuka aykırılık unsurunu birbirine karıştırmamak gerekir. Sahte olarak düzenlenen belgenin özel veya resmi belge niteliğinde olması; elde edilen, ifşa edilen gizli bilginin devlet sırrı niteliğinde olması, suçun değerlendirilebilir unsurlarına örnek oluştururlar. Ancak, suçun konusunun “*hukuka aykırı yolla elde edilmiş organ veya doku*” olması (TCK, m. 95, f. 5) örneğinde olduğu gibi, suç tanımında hukuka aykırılık unsuruna yer verilen çeşitli durumlarda değerlendirilebilir unsurla hukuka aykırılık arasında ilişki kurulabilir. Suçun değerlendirilebilir unsurları ile hukuka aykırılık unsuru arasında manevi unsur bağlamında mevcut olan müştereklik, bu durumda ortaya herhangi bir hukuki sorun çıkarmaz.

Somut olayda bir hukuka uygunluk sebebinin varlığı halinde, artık fiilin hukuka aykırılığından söz edilemeyecektir. Hukuka uygunluk sebepleri, fiilin ve dolayısıyla, suçun hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaktadırlar⁴³⁵. Bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı halinde, fiil ile hukuk düzeni arasında bir çatışmadan söz edilemez.

Bazı durumlarda belirli zararlı faaliyetleri kontrol altına alabilmek için, bunların devletin gözetim ve denetimi altında sınırlı bir şekilde yapılmasına izin verilebilmektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu gibi durumlarda izin, söz konusu faaliyeti icra edenler bakımından bir hukuka uygunluk sebebi oluşturmamaktadır. Örneğin uyuşturucu bağımlısı olan kişiye, bu bağımlılığın etkisini azaltmak, ihtiyaç duyduğu maddeyi meşru olmayan yollarla temine tevessül etmesinin önüne

aykırı olduğunu bilmesi, yani bu konuda **doğrudan kastla** hareket etmesi gerekmektedir.” CGK, 12.11.2013, E. 2013/14-511, K. 2013/449.

⁴³³ ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 104/205; DÖNMEZER/ERMAN II, no. 20; AR-TUK, M. Emin: *Hürriyeti Tahdit Cürmü*, in: Halid Kemal Elbir’e Armağan, 1996, sh. 48 vd. (56).

⁴³⁴ Keza, belirtmek gerekir ki, klasik suç teorisinin etkisindeki yazarlar, “*hukuka özel aykırılık*” olarak nitelendirilen durumlarda, hukuka aykırılığın sübjektif karakterinin varlığını da kabul etmektedirler. Bu yazarlara göre, diğer hukuka aykırılık hallerinde failin kastının suçun hukuka aykırılık unsurunu da kapsamı gerektirdiği halde, hukuka aykırılığın suç tanımında özel olarak belirtildiği durumlarda, failin kastının özel olarak belirtilen hukuka aykırılık hallerini içermesi aranmakta ve somut yargılamada faile herhangi bir ceza yaptırımının uygulanabilmesi için bu hususun da kanıtlanması gerekmektedir (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 694; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 110/111, 113).

⁴³⁵ *Katoğlu*, somut olayda bir hukuka uygunluk sebebinin varlığına rağmen, korunan hukuki değer ihlal edildiğini kabul etmektedir (KATOĞLU, Hukuka Aykırılık, sh. 78). Somut olay bakımından bir hukuka uygunluk sebebinin mevcut olması halinde hukuki değer ihlalinin söz edilmesi çelişkidir.

geçmek ve haksız kazanç yollarının kapatılabilmesi amacıyla, kontrollü olarak, devletin gözetim ve denetimi altında uyuşturucu madde temin edilebilir. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda bağımlı olan kişiye ihtiyacı olan uyuşturucu maddenin verilmesi, tedavi amacına matuf olmadığı için, bu durumda bağımlı kişiye uyuşturucu madde temini fiilinin hukuka uygunluğundan söz edilemez⁴³⁶. Benzer durum bahis oyunları bakımından da söz konusudur. Bu durumları ancak kanuni düzenleme temelli **zorunluluk hali** ile izah etmek mümkün olabilir.

II. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınıflandırılması Sorunu

Hukuk düzeninin birliği ilkesinin gereği olarak, yazılı olsun veya olmasın, bütün hukuka uygunluk nedenlerinin, hukuk düzeninin bütününden ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle, özel hukuk veya kamu hukukundan elde edilen yazılı veya yazılı olmayan hukuka uygunluk nedenleri, doğrudan doğruya ceza hukuku alanında da uygulanacağı gibi, tamamen ceza hukuku alanından kaynaklanan bir hukuka uygunluk nedeni de bütün hukuk dalları açısından *hukuka uygunluk etkisini* doğuracaktır⁴³⁷.

Hukuka uygunluk nedenleri, teorik olarak esas itibarıyla bir *hakkın kullanılması* ve bir *görevin yerine getirilmesi* şeklinde bir ayrıma tabi tutulabilir. Başta meşru savunma olmak üzere çeşitli hak kullanımları birinci kategori hukuka uygunluk sebebine örnek olarak gösterilebilir. Bir *hakka bağlı olarak yetki kullanılması* ve *hukuka uygunluk sebebi oluşturan rızayı* hakkın kullanılması bağlamında ele almak gerekir. *Görevle bağlantılı yetkinin kullanılması* ise, ikinci grubu oluşturan *görevin yerine getirilmesi* hukuka uygunluk sebebi *çerçevesinde ele almak gerekir*. Birinci grubu oluşturan hakkın kullanılması hukuka uygunluk sebebinin kapsam ve sınırlarını her bir hak kullanımı bağlamında ayrı ayrı belirlemek gerekir. Keza, ikinci grup hukuka uygunluk sebebi olarak görevin yerine getirilmesinin, görevle bağlantılı yetkinin kullanılmasının kapsam ve sınırlarını her bir görev bağlamında ayrı ayrı belirlemek mümkündür.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yeni TCK'nın Birinci Kitap, İkinci Kısım, “*Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler*” başlıklı Üçüncü Bölümü altında yer alan ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerin sadece bir kısmı hukuka uygunluk nedeni niteliği taşımaktadır.

Yeni TCK'ya ilişkin Hükümet Tasarısının Birinci Kitap, İkinci Kısım, “*Hukuka Uygunluk Nedenleri*” başlıklı Üçüncü Bölümü altında yer verilen hükümlerin bir çoğunun hukuki niteliği doktrinde tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Doktrinde bazı görüşler ve hatta bazı ülke kanunları, örneğin zorunluluk hâlini bir hukuka uygunluk nedeni değil, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden

⁴³⁶ KILIÇ, Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, sh. 177.

⁴³⁷ JESCHECK/WEIGEND, sh. 327.

olarak kabul etmektedir. Aynı şekilde, yetkili merciin emrini yerine getirilmesinin genellikle bir hukuka uygunluk nedeni olduğu kabul edilirken; bazı görüşler, bu durumda hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin bulunduğunu ve dolayısıyla, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olduğunu ileri sürmektedirler. Doktrinde ileri sürülen görüşler açısından bağlayıcı olmamak için, bu Bölümde söz konusu edilen nedenlerin sonucu göz önünde bulundurulmak suretiyle bir isimlendirmeye gidilmiştir. Belirtilen nedenlerle, ilgili Bölüm başlığı “*Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler*” olarak değiştirilmiştir⁴³⁸.

TBMM Adalet Alt Komisyonunda yürütülen yeni TCK’ya ilişkin çalışmalar sırasında, bu Kısımda, birisi “*Hukuka Uygunluk Nedenleri*”, diğeri ise “*Kusurluluğu Etkileyen Nedenler*” başlığıyla birbirini takip eden iki bölüm oluşturma ve Hükümet Tasarısının “hukuka uygunluk nedenleri” olarak öngördüğü durumların bir kısmının, kusurluluğu ortadan kaldıran veya azaltan neden olarak bu ikinci bölümde yer alması yönünde öneride bulunmamıza rağmen; siyasi irade tarafından bu Bölüm içinde bulunan 24, 25 ve 26. maddelerin konseptinde değişiklik yapılması uygun bulunmamıştır. Bu durum karşısında hiç olmazsa Bölüm başlığının “Hukuka Uygunluk Nedenleri” olarak değil de “*Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenler*” olarak değiştirilmesi yönünde bulunduğumuz ikinci öneri kabul görerek, söz konusu Bölüm başlığı değiştirilmiştir.

Bu Bölüm altında yer alan 24. maddenin birinci fıkrasında bir hukuka uygunluk nedeni olarak, *görevin ifası*; iki ilâ dördüncü fıkralarında ise, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak, *hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi* düzenlenmiştir. Keza, 25. maddenin birinci fıkrasında, bir hukuka uygunluk nedeni olarak *meşru savunmaya*; ikinci fıkrasında ise, kusurluluğu ortadan kaldıran neden olarak *zorunluluk haline* ilişkin hüküm bulunmaktadır. Aslında zorunluluk hali, kişinin davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğini azaltan ve hatta ortadan kaldıran bir etki meydana getirdiği için, kusurluluğu etkileyen bir nedendir. Bu itibarla, zorunluluk haline ilişkin düzenleme yapılırken, bu halin varlığı dolayısıyla, duruma göre kusurunun olmaması nedeniyle faile ceza vermemek veya kusurunun azalmış olması nedeniyle indirilmiş cezaya hükmetmek hususunda mahkemeye takdir yetkisi tanınmak gerekirdi. Ancak, zorunluluk halini de düzenleyen 25. maddenin konseptinde değişiklik yapma yönündeki girişimimiz sonuçsuz kaldığı için, Kanunda bilahare çeşitli suçlar bağlamında ayrıca zorunluluk hali hükümlerine yer verilmiştir (m. 92, f. 1: “*Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sos-*

⁴³⁸ Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nun Türk Ceza Kanunu Tasarısına ilişkin 3.8.2004 tarih ve Esas: 1/593, Karar: 60 sayılı Raporu, TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 228; ÖZGENÇ, İzzet: *Gerekçeli Türk Ceza Kanunu*, Ankara, Kasım 2004, sh. 15.

yal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.”; m. 147, f. 1: “Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi hâlinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.”. Keza, gebelik süresinin on haftadan fazla olmasına rağmen, ananın sağlığını korumaya yönelik “tıbbî zorunluluk” dolayısıyla gebeliğin sona erdirilmesi halinde, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden söz konusudur (m. 99, f. 2).

Yeni TCK’da hukuka uygunluk nedenleri dört ana grupta toplanmıştır. Bunlar,

- 1) *Hakkın kullanılması* (m. 26, f. 1),
- 2) Kanundaki ifade biçimi itibarıyla, “*kanunun hükmünü yerine getirme*” (doğrusu, *görevin yerine getirilmesi*) (m. 24, f. 1),
- 3) *Meşru savunma* (m. 25, f. 1),
- 4) *İlgilinin rızası* (m. 26, f. 2),

hukuka uygunluk nedenleridir⁴³⁹.

III. Yeni Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri

A. Hakkın Kullanılması

Kişinin bir hakkını kullanması, bir hukuka uygunluk nedenidir. Hukuk düzeni bir kimseye belirli bir hakkı kullanma yetkisi verirken, o hakkın icrası fiillerini de hukuka uygun saymaktadır.

Yeni TCK’da, “*Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.*” hükmüne yer vermek suretiyle (m. 26, f. 1), hakkın kullanılması hukuka uygunluk sebebi genel olarak düzenlenmiştir. Bu hükmün gerekçesinde hakkın kullanılmasının bir “*hukuka uygunluk nedeni*” oluşturduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Hukuka uygunluk nedeni olarak hakkın kullanılmasından söz edebilmek için, önce, kişiye hukuk düzenince tanınmış bir sübjektif hakkın varlığı gereklidir. Ayrıca, kişinin bu hakkını, sınırları içinde kullanması gerekir.

Hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeninden söz edebilmek için; kişinin, hiçbir merciin aracılığına gerek olmaksızın, doğrudan doğruya kullanabileceği bir hakkının olması gerekir.

⁴³⁹ “5237 sayılı Kanunun sisteminde; “*meşru müdafaa, hakkın kullanılması, kanunun emrini ifa ve ilgilinin rızası*” şeklinde başlıca dört hukuka uygunluk nedenine yer verilmiştir. Hukuka uygunluk nedenlerinden birinin bulunması, eylemin suç olmasını engelleyeceğinden, fail hakkında **beraat kararı** verilmesi gerekecektir.” CGK, 10.12.2013, E. 2013/1-60, K. 2013/603.

Bu madde kapsamında hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni düzenlendikten sonra; Kanunun Özel Hükümler Kitabında çeşitli suç tanımlarıyla bağlantılı olarak ayrıca hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedenine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Örnek 1. Kanunun 127'nci maddesinde, hakaret suçuyla bağlantılı olarak, isnadın ispatı hukuka uygunluk sebebi düzenlenmiştir.

Anayasamıza göre; kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak isnatta bulunulması durumunda, isnatta bulunan isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir (m. 39). Yine Anayasamıza göre, isnadın doğruluğunun ispat edilmiş olması, hakaret suçunun hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, hakarete bulunan kişi hakkında beraat kararı verilmelidir.

Örnek 2. Kanunun 128'inci maddesinde, bir hukuka uygunluk nedeni olan ve Anayasamızda da güvence altına alınan (m. 36) iddia ve savunma dokunulmazlığı düzenlenmiştir.

Örnek 3. “Suç işlemeye tahrik” başlıklı 214, “Suçu ve suçluyu övme” başlıklı 215, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı 216 ve “Kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı 217'nci “maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.”.

29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla söz konusu madde metninde bu hususa ilişkin olarak yapılan değişikliğin gerekçesi şu şekildedir:

“... bu maddeye eklenen bir cümle ile hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeninin özel bir şekli düzenlenmiştir. Her ne kadar Kanunun 26'nci maddesinin birinci fıkrasında genel olarak hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni düzenlenmiş ise de, çeşitli suçlar bağlamında bu hukuka uygunluk nedenine ilişkin olarak ayrıca hükümlere yer verilmektedir. Bu yöntem ile, hâkimin somut olayda hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeninin varlığını özellikle araştırması gerektiği vurgulanmaktadır.”⁴⁴⁰

Örnek 4.⁴⁴¹ Kanunun 301'inci maddesinde tanımlanan “*Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama*” suçuyla bağlantılı olarak, madde metninde “*Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.*” hükmüne yer verilmiştir.

⁴⁴⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 5/6.

⁴⁴¹ Yeni TCK'nın “Yabancı devlet aleyhine asker toplama” başlıklı 306. maddesinin altıncı fıkrasında, bir hukuka uygunluk nedeni olarak “*meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri*”nden söz edilmektedir.

Yeni TCK'ya ilişkin olarak TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, İktidar ve Anamuhalefet Partisine mensup Milletvekilleri tarafından verilen bir değişiklik önergesi üzerine, bu hüküm madde metnine eklenmiştir. Bu değişikliğin gerekçesi, önerge metninde şu şekilde ifade edilmiştir:

“Eleştiri hakkı Anayasamızda güvence altına alınan ifade özgürlüğünün doğal bir parçası olup, kişilerin bu hakkı kullanmaları sonucu ortaya koydukları düşüncelerin suç oluşturmayaacağı açıktır. Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında da belirtildiği üzere, ağır, sert veya incitici nitelikte de olsa, eleştiri hakkı kullanıldığında kişiye yaptırım uygulanmayacağı, çoğulcu demokrasilerin vazgeçilmez bir gereğidir. Kuşkusuz ki, eleştiri hakkının kullanıldığı bütün hâllerde suç oluşmayacağı; diğer bir deyişle, söz konusu hakkın sadece bu maddedeki suçlar yönünden değil, tüm suçlar için gerekli olduğu açıktır. Nitekim Tasarının 26. maddesinde de “hakkını kullanan kimseye ceza verilmeyeceği” öngörüülerek, eleştiri hakkı da dahil olmak üzere bu konuda genel bir hüküm bulunmaktadır. Ancak, 30.7.2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunla, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 159. maddesine eklenen son fıkrasına, Tasarıda yer verilmemesinin yanlış anlamalara ve uygulamalara neden olabileceği düşünüülerek, maddeye bu hususun dördüncü fıkra olarak açıkça yazılması gerekmiştir.”

Örnek 5. Kitle iletişim araçlarıyla bağlantılı olarak “haber verme” ve eleştiri hakkını da hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni kapsamında değerlendirmek gerekir.

İnsan şahsiyetinin tekâmül edebilmesi için, yaşadığı toplumda ve genel olarak evrende gelişen ve kişiliğin tekamülü açısından önem arzeden olaylar hakkında doğru bir şekilde bilgi edinmesi gerekir (*Bilgi edinme hakkı*)⁴⁴². Basınının da dahil olduğu yazılı, işitsel ve görsel kitle iletişim araçları, kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlayan bir görev ifa etmektedir⁴⁴³.

Kitle iletişim araçlarının görevi, kamuyu aydınlatmaktır; toplumdaki fertlerin kendilerini ilgilendiren hadiseler hakkında bilgilendirilmesidir. Bu bakımdan, yayınlanan haberin *doğru ve gerçeğe uygun* olması gerekir^{444,445}.

⁴⁴² “*Informationsrecht*”.

⁴⁴³ Ayrıntılı bilgi için bkz. İÇEL, Kayıhan. *Kitle Haberleşme Hukuku* (Basın, Radyo-Televizyon, Sinema, İnternet), Yenileştirilmiş ve Geliştirilmiş 4. Bası, İstanbul 1998, sh: 277.

⁴⁴⁴ “Basın, kişinin amme hayatını ilgilendiren fiillerine ilişkin haberleri gerçeklik, kamu yararı, toplumsal ilgi, güncellik ve konu ile ifade sırasında düşünsel bağlılık kurallarına uygun olarak vermek durumundadır. Doğruluğu veya yanlışlığı hakkında, halin özelliklerine uygun bir araştırma yapmadan, gerçeğe aykırı haber yayınlanırsa, *haksız bir tecavüz* sözkonusu olur. Gereken inceleme ve soruşturma yapıldıktan sonra bir haber yayınlanmışsa, sonradan haberin gerçeğe aykırı olduğu anlaşılsa bile, haksız tecavüzden söz edilmez”: 7.CD. 4.11.1991, 10052/12118 (YKD, Şubat 1992, sh. 309 vd.).

⁴⁴⁵ “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 28’inci maddesi uyarınca basın özgürdür. Kamuyu ilgilendiren konularda okuyucuyu objektif ve gerçekleri yansıtarak aydınlatma, yöneticileri eleş-

Yalan; gerçek olmayan, vuku bulmayan bir hususun veya bir vakianın gerçeğe aykırı bir şekilde haber konusu yapılması, bir başkasına aktarılmasıdır. Yalanın temel özelliği, kişinin *kasden* hareket etmesidir. Yalan, her halde ahlâka aykırı bir davranıştır. Yalanın bir başkasının hukukunu etkileyici sonuç doğurması halinde, mesele artık kamuyu ve dolayısıyla hukuk düzenini ilgilendirmektedir. Bir başkasının sahip olduğu değerlere tecavüz niteliğinde olan, bu değerleri tehlikeye maruz bırakan yalan bir haberin yayınlanması halinde; bu haberi yayan kişinin bu nedenle cezaî ve hukuki sorumluluğu cihetine gidilmelidir⁴⁴⁶. Buna karşılık; haberde bir vakıa hakkında gerçek olduğuna inanılarak ve fakat gerçeğe aykırı olarak birtakım bilgilerin verilmesi halinde; kişinin haberin doğruluğunu araştırma hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermiş olup olmadığına

tirme, uyarma, kınama, gereğinde toplumun denetlemesine aracı olma, özgür olan basının görevidir. Hukuk devletinde demokratik düzenin gelişip güçlenmesinde ve hatta kökleşmesinde basının etkisi ve önemi tartışmasızdır. Basın, kamu gücünü elinde tutanlar üzerinde toplumun denetimine ve kamuoyunun oluşumuna aracı olduğu sürece, fonksiyonu, bir kamu görevi niteliğindedir. Basının yansız ve özgür olarak haber verme, bir düşünce ve görüşü tartışma, eleştirme, kamuoyunu aydınlatmaya ilişkin fonksiyonunu yerine getirebilmesi, bazı *ayrıcılıkları* gerektirir. Ancak ne basının özgürlüğü ve ne de bu özgürlüğün sonucu tanınan ayrıcalıklar sınırsız değildir. Tüm özgürlüklerde olduğu gibi, basının özgürlüğü de kişi ve toplum yararı açısından sınırlanacağı tartışmasızdır. Kişinin onur ve saygınlığının korunmasına ilişkin MK.nun 24'üncü maddesi ile BK'nın 49'uncu maddesi, Anayasa'nın 28'inci maddesinde düzenlenen basının özgürlüğünün, özel hukuk alanında sınırlamasıdır.

Basının haber verme fonksiyonunu yerine getirirken kullanacağı bu hakkın özel hukuk alanında sınırı a) Gerçeklik b) Kamu yararı ve toplumsal ilgi c) Güncellik d) Konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık kuralları ile belirlenmiştir. Haber verme hakkı, bu sınırlar içinde kaldığı sürece hukuka uygundur. Haber, anılan temel kurallardan herhangi birine ters düşerse, kamu yararı-kişilik hakları dengesi bozulur. Kullanılan bu hakkın hukuka uygunluğundan söz edilemez.

Yukarıda sözünü ettiğimiz sınırlayıcı temel kurallardan sonuncusu, haber, gerçeği yansıtsa bile, kullanılacak dil ve ifadenin, yapılacak niteleme ve yorumun, haberin verilişinin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı biçim ve ölçüde bulunmasını öngörür. Şayet haberin verilişinde gerekli, yararlı ve ilgili olmayan beyan, tavsif ve değerlendirmelere gidilecek, haberin içeriği ile uygun düşmeyen tahrik edici, yalın bir okuyucu ya da toplumda husumet ve kuşku yaratıcı dil ve ifade kullanılacak olursa, kişilik haklarıyla çatışan basın hürriyetine üstünlük tanınması imkansız hale gelir...": YHGK., 9.10.1985, 4-96/790 (Uygur, Turgut: *Borçlar Kanunu, Genel Hükümler*, CİLT I, Ankara, 1990, sh. 752-753). Aynı doğrultuda kararlar için bkz. Y.4. HD., 26.12.1977, 9260/12506 (Uygur, *Borçlar Kanunu*, I, sh.750 vd.); Y.4. HD., 8.9.1982, 6084/7436, (Uygur, *Borçlar Kanunu*, I, sh.753 vd.); Y.4. HD., 28.4.1987, 2077/3267 (Savaş, Vural/Mollamahmutoğlu, Sadık: *Türk Ceza kanunu Yorumu*, cilt IV, Ankara, Ocak-1995, sh. 4788/4789; Dalamanlı, Lütfi: *Türk Medeni Kanunu*, cilt. I, İstanbul, 1991, sh. 405 vd.; ayrıca, İnal, Nihat: *Medeni Hakların Kullanılması ve Kısıtlanması*, Ankara, 1994, sh.131 vd.); Y. 4. HD., 27.3.1984, 1134/3067 (Uygur, *Borçlar Kanunu*, I, sh.758 vd.).

⁴⁴⁶ Bu düşüncelerimize paralel olarak; mahiyetleri itibarıyla suç oluşturan iftira, suç uydurma, yalan şahitlik, hile, sahtekârlık, dolandırıcılık gibi fiillerin yanı sıra; Kanunda şöyle bir suç tanımına da yer verilmesinde fayda mülhaza etmekteyiz:

"Her kim, bilerek, gerçekleşmemiş bir hususu veya bir olaya ilişkin gerçek olmayan bilgileri herhangi bir şekilde yayarsa; bu haberin kamu güvenliğini, kişilerin hayatını veya malvarlıklarını somut bir tehlikeye maruz bırakması halinde; ... ile cezalandırılır."

bakmamız gerekecektir. Bu tetkikin sonucunda kusurlu olduğu yargısına varılması halinde, kişinin ancak tazminat sorumluluğu cihetine gidilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Fakat, her halde gerçek dışı haberin ilişkin olduğu kişi veya kişiler, cevap ve düzeltme hakkını kullanabilirler.

Kamuyu bilgilendirme görevinin ifası suretiyle verilen haberin ayrıca insan kişiliğinin tekâmülü açısından önem arzemesi gerekir. Hukuk literatürümüzde bu husus, haberin yayınlanmasında “*kamu yararı*” olması ile ifade edilmiştir. Bu itibarla; kişilerin hukuken koruma altına alınan özel (mahrem) hayatına ilişkin bilgilerin, sadece başkalarının tecessüs duygularını tatmine yönelik olarak haber konusu yapılması, tecviz edilemez. Kişinin toplumsal hayat içindeki konumu, ifa ettiği görevin niteliği gözönünde bulundurularak, bu ilkeden belli şahıslar aleyhine sarfınazar edilemez⁴⁴⁷. Meğerki kişi, hukuken tecviz edildiği ölçüde, özel hayatına ilişkin belli bilgilerin açıklanmasına rıza göstermiş olsun.

Kamuyu bilgilendirme görevi yerine getirilirken, haber konusu yapılan olayla ilgili olarak *eleştiri hakkının* kullanılması da söz konusu olabilir. Eleştiri hakkı, kişinin belli bir vakıa hakkındaki düşüncesini açıklama hürriyetinin kullanılmasından ibarettir. Bu itibarla, düşüncayı açıklama hürriyeti açısından yukarıda sözünü ettiğimiz sınırlamalar, eleştiri hakkının kullanılması açısından da aynen geçerlidir⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷ “Kamuoyunda belli durumları yönünden tanınmış olanlar; örneğin sanatkar, politikacı, devlet adamı niteliğindeki kişilerin uğraşları yönünden özel yaşamlarının dokunulmaz ve gizli alanları öteki yurttaşlara göre çok sınırlıdır. Başkalarının yasanın korunması altında bulunması itibarıyla gizliliğine dokunulamayacak olan, özel yaşamlarına oranla bu bölüm kimselerin özel yaşamlarının önemli bir bölümü, toplumun tecessüs ve öğrenme isteklerinden uzak tutulamaz. Bu isteğin başlıca gerçekleşme araçlarından biri de basındır. Bununla beraber, basının bu hakkı salt ve sınırsız değildir. Duyurmadaki bu hakkı, açıkladığı özel yaşamın gerçek dışı hikayelerle süslenmesine veya konu edilen kişiliğin gülünç duruma düşürülmesine olanak sağlayamayacağı gibi, ayrıca bu yolla yayına konu edilen kişinin küçük düşürülmesine, vakar ve haysiyetine, iffetine taarruza olanak sağlamaz.”: Y. 4. HD., 28.11.1974, 10763/16920 (İnal, Nihat: *Medeni Hakların Kullanılması ve Kısıtlanması*, Ankara 1994, sh. 150).

⁴⁴⁸ «Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın tazmini isteğine ilişkindir. Davaya konu yayın, ... Gazetesinin 21.3.1992 günlü nüshasında yapılmıştır. “F.S.nin yaptığı Rumlar yapmadı” başlığı ile yapılan yayında, Kültür Bakanı F.S.nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki tarihi Buğday Camiinin Tiyatro Salonu haline dönüştürüleceğini, bu kararın halk tarafından büyük tepkiyle karşılandığını, artık minberin yerinde çıplakların gösteri yapacağı ve namaz yerine içkili toplantılar düzenleneceğini, bu davranışlara, Rumlar da dahil hiç bir gayrimüslim devletin bile cesaret edemediğini, amaç dışı kullanıma açılan camilerin eski haline getirilmesi gerektiği yazılmıştır.

Davacının başında bulunduğu Kültür Bakanlığının 14.10.1992 tarihli yazısından, KKTC Gazi Magosa’daki Buğday Camiinin tiyatro binasına dönüştürülmesi konusunun, KKTC ... E.S.’nin Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının daveti üzerine 25.2.1992 tarihinde Türkiye’yi ziyareti esnasında misafir bakanın talebi üzerine davacı Kültür Bakanı D.F.S. ile görüşüldüğü ve bu konuda mutabakat sağlandığı, ancak bu mutabakatın herhangi bir protokol veya anlaşmaya dercedilmediği anlaşılmaktadır. Bu ziyaret sırasında iki devlet kültür bakanları arasında imzalanan mutabakat tutanağının tetkikinden, Türkiye Cumhuriyeti’nin anlaşmaya varılan hususlarda KKTC’ne gerek uzman temin etmek, gerekse malî kaynak sağlamak suretiyle destek verdiği an-

laşılmaktadır. KKTC’ndeki Buğday Camiinin tiyatro binasına dönüştürülmesi hususundaki iki kültür bakanı arasında görüşülerek anlaşmaya varıldığı hususunda bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC. arasındaki bugüne kadar gelişen ilişkilerin ve iki bakan arasında imzalanan tutanağın da bir arada değerlendirilmesinden anlaşmaya varılan bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ne mali destek sağlayacağından şüphe yoktur. Aslında bağımsız bir devlet olan KKTC. Kültür Bakanının Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı ile bu konuda mutabakat sağlamasından amaç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden mali destek sağlamaktır. Diğer yandan, hangi dine mensup olursa olsunlar insanlar gerek kendi, gerekse başka dine mensup olan insanların ibadet ettikleri yerlere saygı gösterirler. Savaşlarda dahi ibadethanelere yapılan saldırılar bir insanlık suçu olarak kabul edilir. Bu anlayışın sonucudur ki, kendi kilisesine başı açık ve ayakkabısı ile giren bir Hristiyan, camiye girerken İslâm kurallarına uyararak ayakkabılarını çıkarır, kadınsa başını örter. Nüfusumuzun yüzde doksandokuzu İslâm Dini’ne mensuptur. İslâm Dini’nde cami “Allah’ın evi” kabul edilen kutsal bir yerdir. Diğer dinlere mensup insanların kendi ibadethanelerine gösterdiği saygı ve hassasiyeti Müslümanlar da ibadethaneleri olan camilere gösterirler. Bir zamanlar Osmanlı hakimiyetinde bulunan bir kısım Avrupa toprakları bugün dini Hristiyan olan Avrupa Devletlerinin idaresinde olmasına rağmen, Müslümanların bu konuda duydukları hassasiyet nedeniyle, gerek gösterecekleri tepkiden çekinilerek, gerekse ibadet edilen yerlerle ilgili oluşan bu ortak insanlık değerinden ötürü başka bir amaca yönelik olarak kullanılmamış, sadece ibadete kapatılmakla yetinilmiştir. İbadete kapatılma ve tamir edilmeyerek yıkıma terk edilme olayı dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve halkının tepkilerine sebep olmuştur. Bir dönem tamamı Rum hakimiyetinde bulunan Kıbrıs adasında da durum böyledir. Rumlar, camilerin amacı dışında kullanılması yolunda bir davranışta bulunamamışlardır. Hal böyle iken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kültür Bakanı olan davacının habere konu olan caminin tiyatro binasına dönüştürülmesi konusundaki sakıncaları diğer bakana anlatarak uyarması gerekirken, bu konuda görüş birliğine varması eleştirilecek bir davranıştır. Devlet yönetiminde meydana gelecek usulsüz ve devlet politikasına uygun düşmeyen işleri kamuoyuna duyurmak ve bu yolda tartışmaları başlatmak ve yapmak basın görevleri arasındadır. Davacı tamamen kendi iradesiyle yarattığı bu ortamın basın yoluyla eleştirilmesine katlanmak zorundadır. Dava konusu olan yazı gerçek olaylara dayandığından, böyle bir olayın basın yoluyla kamuoyu önünde tartışılmasında kamu yararı vardır. Konu ele alınıp açıklanırken kullanılan sözcükler de ele alınan konunun gereği olduğu için amaç bakımından olduğu kadar araç bakımından da aşırıktan söz edilemez. Diğer bir deyişle, yayında konunun duyarlılığına denk düşen uygun araçlar kullanılmıştır. Tüm bu nedenlerle basının haber verme ve aydınlatma özgürlüğü sınırları içinde kalan yazının hukuka uygun olduğu kabul edilerek davanın reddi gerekirken, kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesi ile kabulüne karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

Muhalefet Şerhi: Davacı, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu belirterek 250 milyon lira manevi tazminata hükmedilmesini istemiştir. /// Mahkemece, verilen haberde küçültücü, davacıya karşı husumet yaratıcı gibi ifadeler kullanıldığından bahisle, istemin kısmen kabulüne hükmedilmiştir.

Hüküm, davalı yanca temyiz edilmiştir.

Habere konu olan olay, KKTC’de bulunan Buğday Camii binasının aynı ülke Kültür Bakanının tiyatro binasına dönüştürülmesi ve bu amaçla maddi yardım talebinin davacı Kültür Bakanınca kabul edilmesine ilişkin bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla, KKTC. Kültür Bakanı, TC. Kültür Bakanından, cami olan bir yerin tiyatro binası olarak kullanılması gerektiğini, bu yüzden TC. Hükümeti’nden davacı Kültür Bakanı aracılığı ile maddi yardım talebinde bulunduğunu, bu yardım isteminin davacı bakan tarafından kabul edilmesinin Müslümanlığın dini kuralları ile bağdaşmadığı esastan kaynaklanmaktadır.

İşte bu olgulardan hareket eden davalı yayın organı gazetenin birinci sayfasının en üst başlığında, gazete adının da üstünde, sekiz sütun üzerinde, önce küçük puntolarla “*Kıbrıs’ta tiyatroya dönüştürdüğü Buğday Camii’nde ibadet yerine çıplaklar gösteri yapacak ve içki içilecek*” onun altında yine sekiz sütun üzerinde büyük manşetle “*F.S.nin yaptığını Rumlar yapmadı*” başlığı yer almış, alt yandada, davacının da desteği ile, “... *Buğday Camii’nde artık*

minberin yerinde çıplaklar gösteri yapacak ve namaz yerine içkili toplantılar düzenlenecek...” sözleri yer almıştır.

Anayasanın 28. maddesinde; basının özgür olduğu, sansür edilemeyeceği, Basın Kanununun 1. maddesinde de, “basın serbesttir” sözcükleri yer almıştır. Basına verilen önemin nedeni, kişinin habere ulaşma hakkı ile tanınan iletişim hakkının bir insan hakkı olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun içindir ki, bu hak koruma altına alınmıştır.

Bu denli geniş işlevi olan ve bir kamu görevi yürüttüğü kabul edilen basının özgür olması tartışılmaz. Ne var ki, bu özgürlük de tüm diğer özgürlükler gibi, sınırsız değildir. Bu özgürlük, mutlak olmayıp nisbidir. Basın özgürlüğünün önüne kişinin, kişilik hakları çıktığında, basın geri çekilmek ve orada durmak zorundadır. Bu husus, MK’nın 24 ve 24/a maddesi ile güvence altına alınmış, yaptırımını açıklamıştır. Ayrıca, BK’nun 49. maddesinde de, saldırı halinde, manevî tazminat istenebileceği genel bir kural olarak düzenlenmiştir. Şu hususu da belirtelim ki, kişinin kişilik haklarına dokunamama da nisbidir. Olaya ve kişiye göre değişiklik gösterebilir. Haber gerçekse, gerçeklik ölçüsü içinde bu, uygun bir dille sınırı aşılmamak suretiyle yayınlanabilir. Bu halde saldırının varlığından söz edilemez. Çünkü, basının görevi doğru olan haberi vermektir.

Somut olayda, Müslüman ve bağımsız olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile milli kültür ve bağlılık ilişkileri bulunan bir ülkenin Kültür Bakanının ülkesindeki bir caminin tiyatro binasına dönüştürülmesi konusundaki yardım isteminin davacı bakan tarafından kabul edildiği veya kabul edilmiş aşamasında bulunduğu anlaşılmaktadır. Burada, TC. Hükümeti’nin bakanının cevabı evet ve hayır olabilir. Onu uyarmak, o devletin bağımsızlığına saygı göstermemek sonucunu doğurabilir. O yeri tiyatro binasına dönüştürmek veya dönüştürmemek o ülke yöneticisinin ve politikasının bir tercihidir. Onun sorumluluğunu yüklenmek o ülke bakanını ve mensubu hükümetin bir sorunudur.

Gerçek bu iken, davalı gazetenin yukarıda yazılı olduğu üzere, haberi yansıtmaması davacı kişiyi kendi ülkesinde din düşmanı, savaş yapmadan masum insanları öldüren Rum halkından daha kötü, zalim, acımasız göstermesi, haberin sınırları içinde kalınarak verildiği kabul edilemez. Bir kişi, bağımsız bir devletin bakanından gelen bir teklifin eleştirisini yapmadı diye, bu kadar ağır bir dille suçlanması, hatta hedef gösterilmesinde haber verme sınırlarının aşıldığı açıktır. Çünkü, davalı yayın organı bu denli ağır olan sözcükleri kullanmadan da aynı haberi duyurma ve etkinliği sağlama olanağını elde edebilirdi. Haberin bir verilmiş amacı vardır. İşte bu amaç ve sınır içinde kalınarak verilmelidir. Bu sorumluluğu aşan ve kişinin şeref ve haysiyet ve yaşama hakkını ihlâl eden açıklamalar hukuka uygun değildir. Davalı taraf, başka ifadeler ve açıklama biçimi ile davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulmadan, aynı amaca ulaşmak veya onun için daha az zarar verici bir yol seçmek suretiyle haberi verebilirdi. Çünkü, kişilik hakları basın yoluyla ihlâl edilenin, kamu yararının zorunlu kıldığından daha fazlasına katlanması ondan istenemez. Bu nedenle, ilgiliye en az zarar verecek açıklama şeklinin seçilmesi gerekir. Aksi halde amaçla araç arasındaki orantıdan söz edilemez. Yayının içeriği doğru olsa bile, haberin verilmiş biçimi, o doğrunun dışına çıkarak, aşağılayıcı ve abartılı ise, yayının hukuka aykırılık sınırları içine girdiğinin kabulü gerekir.

Somut olayda, orta düzeydeki bir okuyucu, davacının savunmasız insanları öldüren Rumlardan da kötü davrandığını düşünebilir. Çünkü, kullanılan sözcükler haberin yer aldığı sayfa, açıklamanın genişliği, harflerin diziliş biçimi herkesi kolayca bu sonuca götürür. Olayda, davacının bu tür bir yayına muhatap olmasını gerçek ve haklı gösterecek ölçüde bir davranış içinde bulunduğu kabul edilemez. Davalının davranışı, dost bir ülkenin kültür alanındaki bir yardım istemine olumlu yanıt vermekten ibarettir. Tiyatroya dönüştürülmesi düşünülen cami, gerek nüfus itibarıyla, gerek yerdeki konumu itibarıyla öylece kalması uygun görülmemiş olabilir. Müslüman bir toplum için caminin önemi tartışılmaz. Ancak, bunun o an için, artık o amaç için kullanılmayacağı gerçeği karşısında, başka ve yine bir kültür hizmeti olan tiyatro olarak kullanılmasını, dine aykırı bir davranış olarak kabul etmemek gerekir. Cami, toplumun hoş karşılamayacağı, bir kumarhane, bir diskotek gibi işyerine dönüştürülmesi düşünülmemiş ki, davacının bu kadar ağır eleştiriye muhatap olması hoşgörü ile karşılanabilsin.

B. Görevin Yerine Getirilmesi

Yeni TCK'nın 24. maddesinin birinci fıkrasında “*kanun hükmünü yerine getirme*” adıyla bir hukuka uygunluk nedenine yer verilmiştir:

“Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.”

Kanun hükmü kişiye herhangi bir konuda bir hak veya yetki vermişse, bunun öngörüldüğü şekilde uygulanması durumunda hukuka aykırılık söz konusu olmaz.

Buradaki “*kanun*” deyiminden pozitif hukuk metinlerini yani “*yazılı hukuk kuralları*”nı anlamak gerekir.

Kanun kişiye belli hususlarda bir *yükümlülük* yüklemiş olabilir. Bu yükümlülükler, TCK'daki suç tanımlarının mefhumu muhalifinden yani karşıt anlamından çıkmaktadır.

Örneğin yeni TCK'ya göre, “*Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de, yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.*” (m. 279, f. 1). Bu düzenlemeyle, bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenen kamu görevlisine, bu suçla ilgili olarak bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Keza, “*Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hâl ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhâl ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.*” (m. 98, f. 1). Bu suç tanımıyla, kendini idare edemeyecek durumda bulunan bir kimseyle karşılaşan kişiye yardım etme veya ilgili makamlara bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Esasında suç oluşturan fiiller, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen usul ve koşullarda bir koruma tedbiri olarak icra edildikleri takdirde, kanundan kaynaklanan bir *yetki* kullanılmakta olduğu için, hukuka uygundur. Örneğin haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu bağlamında, postada elkoyma (CMK, m. 129) ve telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenmesi koruma tedbirleri (CMK, m. 135 vd.) kapsamında gerçekleştirilen fiiller, hukuka uygundur.

Aslında, kanunun hükmünün yerine getirilmesinin söz konusu olduğu hallerde, kişi açısından bir *görev* vardır. Bu itibarla, yukarıdaki örneklerde “**görevin ifası**” veya “**görevin yerine getirilmesi**” hukuka uygunluk nedeninden söz etmek daha doğru olacaktır. Çünkü, bir davranışın hukuka uygun olup olmadığını belirlerken, yerine getirilen görevin mahiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak yürütülen görevle bağlantılı olarak, bu hukuka uygunluk nedeninin sınırının aşıp aşılmadığını belir-

Açıklanan nedenlerle, haberin verilmesinde sınır aşımak suretiyle, kişilik haklarına saldırının varlığı kabul edilmelidir.»: 4. HD., 23.2.1993, 3762/15152 (YKD, Temmuz 1994, sh.1067 vd.).

lemek mümkün olabilecektir. Her ne kadar, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, bazı durumlarda bir *yetki* kullanılması söz konusu ise de; bu yetkinin bir görevle bağlantılı olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Sorunun sadece “*kanunun cevaz verdiği hal*” olarak görülmesi, bu sınırı objektif olarak belirlemeyi güçleştirmektedir.

Ekskurs 1. Kolluk Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi

Bir hukuka uygunluk sebebi olarak görevin ifası (yerine getirilmesi) bağlamında kolluk görevlileri, **zor ve silah kullanma yetkisine** sahiptir.

Hukuk, belli bir hususta **görev** yüklenen kişinin bu görevi yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde **yetki** ile donatılmasını gerekli kılmaktadır. Keza, kişi yetkili kılındığı ölçüde de **sorumluluk** altına girmektedir. Bu ilişki kısaca, “**ne kadar görev varsa, o kadar yetki; ne kadar yetki varsa, o kadar sorumluluk**” şeklinde ifade edilebilir.

Kolluk görevlileri, görevlerinin gereği olarak, zor ve silah kullanma yetkisi ile donatılmışlardır.

Zor, kişinin kendisine terettüp eden belirli bir yükümlülüğün gereklerine uygun davranmaması halinde, bu yükümlülüğün gereklerine uygun davranmasını sağlamak amacıyla ve ancak kanunla verilen yetkiye dayalı olarak kullanılabilir. Bu bakımdan, zor kullanma yetkisinin mutlaka **kanuni** bir **dayanağı** olmalıdır.

Mesela, ceza muhakemesi sürecinde “*usulüne uygun olarak çağrılıp da mazaretini bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirilir ...*” (CMK, m. 44, f. 1). Keza, kolluk görevlileri, belli koşulların varlığı halinde, şüpheli veya sanığı da zorla getirme **yetkisine** sahiptir (CMK, m. 146, 176). Bu itibarla, davet edilen kişinin bu davete icabet etmemesi nedeniyle mahkemece **zorla getirilmesine karar verilmesi** veya Cumhuriyet savcısı tarafından **zorla getirilmesinin emredilmesi** halinde (CMK, m. 43, 44, 146, 176); bu kişiye karşı, kararı veren mahkeme veya emri veren Cumhuriyet savcısı nezdinde **hazır bulundurulmasını sağlamak amacıyla** ve **gelmemek yönündeki direncini kırarak ölçüde** zor kullanılabilir. Kolluk görevlileri bakımından bu durumda **görevin ifası hukuka uygunluk sebebi** söz konusudur^{449,450}.

⁴⁴⁹ 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı “**Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu**”nun 2.6.2007 tarihli ve 5681 sayılı Kanunla değiştirilen “**Zor ve silah kullanma**” başlıklı 16. maddesine göre,

“(1) Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kırarak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir.

(2) Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir.

(3) İkinci fıkrada yer alan;

a) *Bedenî kuvvet; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedenî gücü,*

b) Maddi güç; polislin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında kullanıldığı kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, polis köpekleri ve atları ile sair hizmet araçlarını,

ifade eder.

(4) Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtar yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir.

(5) Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir.

(6) Polis, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunur.

(7) Polis;

a) Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında,

b) Bedenî kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde,

c) Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde,

d) Kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde, silah kullanmaya yetkilidir.

(8) Polis, yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde "dur" çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir.

(9) Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilir.”

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5681 sayılı Kanunun çerçeve 4. maddesiyle değiştirilen 16. maddesinin Kanun Teklifindeki **gerekçesi** şu şekildedir (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1437, sh. 7 vd.):

“Zor kullanma, polislin kolluk kuvveti olması dolayısıyla diğer kamu görevlilerinden farklı olarak sahip olduğu temel yetkisidir. PVSK’nın ek 6’ncı maddesinde öngörülen bu yetki, yenden ve daha açık şekilde bu maddede düzenlenmiş bulunmaktadır.

İlk fıkrafta, polislin, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu **direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde** zor kullanmaya yetkili olduğu gösterilmektedir. Buradaki direniş, polislin tüm görevlerinin ifası sırasında karşılaşılan direnişi ifade etmektedir. Örneğin durdurulması gereken bir aracın durmayarak kaçtığı durumlarda, bu aracın durdurulması da bu kapsamdadır. Ayrıca zor kullanan **polise, aktif şekilde direniş gösteren kişinin bu eylemi, meşru savunma kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu aktif direniş, Türk Ceza Kanununun 265’inci maddesi kapsamında ayrıca suç oluşturmaktadır.**

İkinci fıkrafta, zor kullanma yetkisinin derece ve kademeleri gösterilmektedir. Buna göre zor kullanma yetkisi; bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanmadan oluşmaktadır. Bunlar, di-

renmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette kullanılacaktır.

Ayrıca zor kullanmanın direnmeyle orantılı olması, aynı nitelik ve derecede değil, **direnmeyi etkisiz kılacak ölçüde** güç kullanımını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, zor kullanmada amaç, direnen kişileri etkisiz hale getirmektir. Kullanılacak kuvvetin derecesi, direnmenin ve saldırının derecesine bağlıdır. Direnme ne kadar fazla ise, kullanılacak kuvvetin derecesi de o kadar fazla olacaktır. Polis, etkisiz hale getirme için sahip olduğu metotlara kademeli olarak başvuracak, polisin seçtiği metodun, her zaman, derece olarak direnmeden üstün olması gerekecektir. Aksi takdirde, saldırı ve direncin etkisiz hale gelmesi söz konusu olamayacaktır. Dolayısıyla bu madde kapsamında zor kullanma yetkisi, direnme veya saldırıda kullanılan ile aynı nitelikte zor veya silah kullanılması anlamında yorumlanamaz. Polis, direnme veya saldırıyı defedecek üstünlükte zor veya silah kullanır.

Maddenin üçüncü fıkrasında, bedeni kuvvet ve maddi gücün ne olduğu gösterilmektedir. Zor kullanma sırasında, bedeni kuvvetin dışında; fıkarda belirtildiği gibi kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve atları ile sair hizmet araçları maddi güç olarak kullanılabilir.

Dördüncü fıkraya göre, zor kullanmadan önce, doğrudan doğruya **zor kullanılacağı ihtar** yapılacak; ancak direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir.

Polisin, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki araç ve gereçlerden hangisini kullanacağını ve zorun derecesini kendisinin takdir ve tayin edeceği; ancak, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki araç ve gereçlerden hangisinin kullanılacağını müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edileceği de beşinci fıkarda düzenlenmiştir.

Altıncı fıkarda da, polisin, kendisine veya başkasına yönelik bir **saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunacağı** belirtilmiş bulunmaktadır.

Zor kullanmada olduğu gibi, kolluk kuvveti olarak polisin ayırt edici yetkilerinden birisi olan **silah kullanma**, maddede yeniden düzenlenmektedir.

Yedinci fıkarda üç temel durumda polisin silah kullanma yetkisinin olduğu belirtilmektedir. Bunlardan ilki meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında silah kullanma; ikincisi bedeni kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu direnişi kırmak amacıyla ve kırarak ölçüde silah kullanma; üçüncüsü ise yakalanması gereken kişinin yakalanması amacıyla ve yakalanmasını sağlayacak ölçüde silah kullanmadır.

Silah kullanılacak hallerden üçüncüsü olarak gösterilen durumla ilgili olarak sekizinci fıkarda ayrıca bir sınırlamaya gidilmiş; bu durumlarda öncelikle “dur” çağrısının yapılması, buna rağmen kişinin kaçması halinde uyarı amacıyla silahla ateş edilebilmesi; bu uyarı atışına rağmen hala kaçmakta ısrar etmesi ve kaçması dolayısıyla **ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde, yakalanmasının sağlanması amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilmesi** öngörülmüştür.

Maddenin dokuzuncu fıkrasında da, zor veya silah kullanma yetkisinin kullanılması sırasında, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, polisin, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı **saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçü ve oranda duraksamadan silahla ateş edebileceği** düzenlenmiştir.”

⁴⁵⁰ 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı “**Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu**”nun (RG: 12 Mart 1983/17985) “**Silah kullanma yetkisi**” başlıklı 11. maddesine göre, “**Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası sırasında hizmet özelliğine uygun ve görevin gereği olarak kanunlarda öngörülen silah kullanma yetkisine sahiptir.**”

Bakanlar Kurulu’nun 3.11.1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Kararı ile kabul edilen “**Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği**”nin (RG: 17 Aralık 1983/18254) 38. maddesinde zor kullanma yetkisi, 39 ve 40 maddelerinde ise silah kullanma yetkisi düzenlenmiştir.

Önemle işaret etmek gerekir ki, hukuki dayanakları gösterilerek usulüne göre verilmiş **zorla getirme kararı olmadan, kolluğun re'sen zorla getirme yetkisi bulunmamaktadır**.

Şüpheli veya sanığın çağırılması ya da hapis cezasına mahkum olmuş olan hükümlüye cezasının infazı amacıyla “çağrı kağıdı”nın tebliği sürecinde kendisine ulaşılamadığı takdirde veya hükümlünün tebellüğden imtina etmesi halinde, **yakalama kararı** çıkarılabilmektedir (İnfaz Kanunu, m. 20, f. 2; İnfaz Yönetmeliği⁴⁵¹, m. 54, f. 2).

Keza, soruşturma ve kovuşturma evresinde **tanık** olarak dinlenmesi gereken kişinin çağırılması işlemlerinin yerine getirilmesinde kolluğun görevlendirilmesi de, uygulama bakımından bir sorun çıkarmamaktadır. Usulüne uygun çağırının yapılmasına rağmen kişinin çağrıya icabet etmemesi halinde, çağırının kendisine tebliği için kişiye ulaşılamadığı takdirde veya kişinin tebellüğden imtina etmesi halinde, hakkında **zorla getirme kararı** verilebilmektedir (CMK, m. 43, m. 44, m. 146, f. 7).

Bu kararı vermeye, mahkeme, hakim ve Cumhuriyet savcısı yetkilidir (CMK, m. 145, 146).

Aynı şekilde, hukuk davasında tanık olarak dinlenmesine karar verilen kişi, usulüne uygun olarak çağırılmasına rağmen çağrıya icabet etmemesi halinde, “zorla getirilir” (HMK, m. 245).

Kolluk görevlileri, ayrıca, sahip bulundukları **yakalama yetkisi bağlamında zor kullanma yetkisini** haizdirler (CMK, m. 90)⁴⁵².

Ancak belirtmek gerekir ki, **Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda** jandarmanın “**kanunlarda öngörülen silah kullanma yetkisine sahip**” olduğu belirtilmesine rağmen, söz konusu Yönetmelikte zor kullanma yetkisinin yanı sıra silah kullanma yetkisi düzenlenmiştir. Kanımızca, zor ve silah kullanma yetkisine ilişkin olanak söz konusu Yönetmelikte yer alan bu düzenlemelerin anayasal ve kanuni dayanağı bulunmamaktadır. Zor ve silah kullanma yetkisine ilişkin olarak yönetmelikle düzenleme yapılması, Anayasa’nın kişi hak ve hürriyetlerine ilişkin olarak ancak **kanunla** sınırlama ve düzenleme yapılabileceği hususundaki genel ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 2.6.2007 t. ve 5681 s. Kanunla değiştirilen 16. maddesi hükmü ile bu Kanundaki yetkilerin jandarma tarafından da kullanılacağına dair 25. maddesi hükmü karşısında “**Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği**”nde zor ve silah kullanma yetkisine ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yer almasına da gerek kalmamıştır.

9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı “**Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu**”nun (RG: 13 Temmuz 1982/17753) 5. maddesinde silah kullanma yetkisiyle ilgili genel bir hükme yer verilmiştir: “*Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin yapılmasında; silah kullanma yetkisi dahil kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.*” (fıkra 1).

⁴⁵¹ Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan “*Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik*” (RG: 29 Mart 2020/31083).

⁴⁵² Ceza Muhakemesi Kanununa göre; “a) Kişiye suçu işlerken rastlanması, b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının

Keza, kolluk görevlileri, hukuka aykırı olarak, mesela geceleyin insanların istirahatata çekildikleri bir saatte meydan, cadde ve sokaklarda toplantı düzenlenmesi halinde, toplanan kişilerin **dağılmalarını sağlamak amacıyla** ve **sağlayacak ölçüde zor kullanma yetkisini** haizdirler. Hukuka aykırı bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılmasını sağlamak amacıyla zor kullanma yetkisi, 6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı “*Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu*”nun 24. maddesinin ikinci ve altıncı fıkralarında düzenlenmiştir⁴⁵³. Bu düzenlemeye göre:

- a) Toplanan veya gösteri yürüyüşü yapan kişiler dağılmaları için önce **uyarılacaklardır**. Bu uyarı yapılırken, topluluğu oluşturan kişilere, dağılmaları, dağılmadıkları takdirde kendilerine karşı zor kullanılacağı ifade edilir.
- b) Uyarıya rağmen dağılmadıkları takdirde, topluluğu oluşturan kişilere karşı, **dağılmalarını sağlamak amacıyla** ve **sağlayacak ölçüde zor kullanılır**⁴⁵⁴.

bulunmaması” hallerinde, herkese yakalama yetkisi tanınmıştır (m. 90, f. 1). Bu düzenleme ile suçüstü halinde herkes şüpheli kişiyi yakalamak hususunda yetkili kılındığına göre; bunun zorunlu sonucu olarak, yakalamayı gerçekleştiren kişi de, şüphelinin kaçmasını önlemek amacıyla olarak ve kaçmamasını sağlayacak ölçüde zor kullanma yetkisini haizdir.

⁴⁵³ 2911. sayılı Kanunun “*Toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması*” başlıklı 24. maddesi şu şekildedir:

“Madde 24- Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 23’üncü maddede belirtilen kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vukubulması sebebiyle, Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşü haline dönüşürse:

a) *Hükümet komiseri toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini bizzat veya düzenleme kurulu aracılığı ile topluluğa ilan eder ve durumu en seri vasıta ile mahallin en büyük mülki amirine bildirir.*

b) *Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gönderir.*

Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar eder. Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Bu gelişmeler hükümet komiserince tutanaklarla tespit edilerek en kısa zamanda mahallin en büyük mülki amirine tevdi edilir.

(a) ve (b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuvvetlerine karşı fiili saldırı veya mukavemet veya korudukları yerlere ve kişilere karşı fiili saldırı hali mevcutsa, ihtar gereksizdir ve zor kullanılır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne 23’üncü madde (b) bendinde yazılı silah, araç, alet veya maddeler veya sloganlarla katılanların bulunması halinde bunlar güvenlik kuvvetlerince uzaklaştırılarak toplantı ve gösteri yürüyüşüne devam edilir. Ancak, bunların sayıları ve davranışları toplantı veya gösteri yürüyüşünü Kanuna aykırı addedilerek dağıtılmasını gerektirecek derecede ise yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç, alet veya maddeler veya sloganlarla katılanların tanınması ve uzaklaştırılmasında düzenleme kurulu güvenlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdür.

Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin Kanuna aykırı olarak başlaması hallerinde; güvenlik kuvvetleri mensupları, olayı en seri şekilde mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle beraber, mevcut imkanlarla gerekli tedbirleri alır ve olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri amiri, topluluğa dağılmaları, aksi halde zor kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bulunur ve topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır.”

⁴⁵⁴ 2911 sayılı Kanunun 32. maddesi 22.7.2010 tarihli ve 6008 sayılı Kanunla (Resmi Gazete: 25 Temmuz 2010/27652) başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Zor kullanma yetkisi ile bağlantılı olarak, kolluk görevlilerinin silah kullanma yetkisini de incelenmek gerekir. Kolluk görevlileri, görevlerinin gereği olarak silahla donatılmıştır. Mahiyetleri farklılık arz etse bile, kolluk görevlileri, sahip bulundukları zor kullanma yetkisinin gereği olarak, bir saldırıyla ya da direnişle karşılaşmalarını önleme bakımından caydırıcı etki doğurması itibarıyla görünür bir şekilde silahla donatılmışlardır.

Kolluk görevlileri, kendilerine veya başkalarına karşı gerçekleşen saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla silah kullanabilirler. Bu durumda herkesin sahip bulunduğu meşru savunma (meşru müdafaa) hukuka uygunluk sebebinin varlığı söz konusudur. Meşru savunmanın varlığı ve şartları bakımından kolluk görevlileri ile herhangi bir insan arasında fark bulunmamaktadır⁴⁵⁵. Meşru savunma hukuka uygunluk sebebinin varlığı halinde, kolluk görevlilerinin zor veya silah kullanma yetkisini düzenleyen kanun hükümlerine müracaat etmeden, doğrudan TCK'nın meşru savunmaya ilişkin hükümlerine dayalı olarak değerlendirme yapmak gerekir. Bu itibarla, kolluk görevlileri gerek kendilerine karşı gerek sair kişilere karşı gerçekleşmekte olan ya da gerçekleşmesi muhakkak olarak öngörülen bir **saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla** ve bu **saldırıyı etkisiz kılmak ölçüde** savunma hareketi gerçekleştirebilir. Bu savunma hareketi hukuka uygundur. Örneğin, maddi menfaat elde edilmesi için bir işadınının oğlunun kaçırılması halinde, kolluk görevlileri rehineyi kurtarmak amacıyla ve kurtarmaya yetecek ölçüde rehin alan kişiyi hedef ittihaaz ederek silahla ateş edebilirler. Bunun için, rehinenin başka türlü kurtarılma imkânının mevcut bulunmaması gerekir. TCK'nın meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde bu fiilin hukuka uygun olduğunu kabul etmek gerekir.

Kolluk görevlileri, bir saldırı durumu ve dolayısıyla meşru savunma halinde olmadan da, belirli hallerde silah kullanma yetkisini haizdirler. Silah, bazı hallerde zor kullanma yetkisi bağlamında kullanılabilir. Bu itibarla, kolluk görevlileri, zor kullanma yetkisi kapsamında ve bu yetkinin sınırları dahilinde silah da

“Direnme

MADDE 32– *Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtar ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçu, toplantı ve gösteri yürüyüşünü tertip edenlerin işlemesi halinde, bu fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur.*

İhtar ve zor kullanmaya rağmen kolluk görevlilerine karşı cebir veya tehdit kullanılarak direnilmesi halinde, ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265'inci maddesinde tanımlanan suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.

23'üncü maddede yazılı hallerden biri gerçekleşmeden veya 24'üncü madde hükmü yerine getirilmeden yetki sınırı aşılarak toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin dağıtılması halinde, yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri işleyenlere verilecek cezalar, dörttebire kadar indirilerek uygulanabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.”

⁴⁵⁵ 2911 sayılı Kanunun 24. maddesinin üçüncü fıkrasındaki “zor kullanma yetkisi”ni bu bağlamda değerlendirmek gerekir.

kullanabilirler. Ancak, belirtilmek gerekir ki, burada söz konusu olan, silahın ateşli silah olması şart değildir.

Kolluk görevlileri, hakkında yakalama veya tutuklama kararı verilmiş ya da hapis cezasına mahkum edilmiş olan bir kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla da silah kullanabilirler. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda hakkında yakalama veya tutuklama kararı verilmiş ya da hapis cezasına mahkum edilmiş olan bir kişinin yakalanmamak için kaçması söz konusudur. Bu itibarla, kolluk görevlileri **kaçan bir kişiyi yakalamak için silah kullanma** yetkisiyle donatılmıştır.

Ancak, bunun için yakalanmak istenen kişinin **hedef ittihaz edilerek** silahla **ateş** edilmesine gerek yoktur. Örneğin kaçmakta olan bir kişinin teslim olmasını sağlamak için silahla **havaya ateş** edilebilir.

Bu bağlamda sorun, **kaçan kişi hedef ittihaz edilerek silahla ateş edilebilip edilemeyeceği** hususunda temerküz etmektedir.

Öncelikle belirtilmek gerekir ki, **başka suretle ele geçirilmesi imkanı mevcut ise, kaçan kişiye karşı hedef ittihaz edilerek silahla ateş edilemez**⁴⁵⁶. Ancak, örneğin geceleyin suçüstü halinde kimliği henüz belirlenememiş olan şüphelinin kaçması halinde, kimliği belirlenemediği için, bu kişiye karşı, yakalanmasını

⁴⁵⁶ Polis memurları S ile A, motosikletle seyir halinde olan M ve H'den şüphelenir ve “dur” ikazında bulunur. M motosikleti durdurmayınca polisler tarafından takip edilirler. Takip edildiklerini gören M motosikletini durdurur ve H, motosikletten inerek polisler doğru yürür. M tekrar motosikletle kaçıma başlar. S, motosikletin arkasından bir süre koşarak M'ye tekrar “dur” ihtarında bulunur. M durmaz. Bunun üzerine S, takriben dört metre mesafeden tabancasıyla M'yi hedef alarak iki el ateş eder. M, ensesinden aldığı bir kurşun yarası ile olay yerinde ölür.

Esas Mahkemesi S hakkında olası kastla öldürme suçundan dolayı (TCK, m. 21, f. 2 ve m. 81) mahkûmiyet hükmü kurar.

S'nin müdafii, olayda S bakımından kanunun hükmünü yerine getirme hukuka uygunluk sebebinin varlığını (TCK, m. 24), ancak S'nin bu hukuka uygunluk sebebinin sınırını aştığını (TCK, m. 27) ve keza bu hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında hataya düştüğünü (TCK, m. 30) ileri sürerek, hükmü temyiz eder.

Yargıtay C. Başsavcılığı, S'nin olası kastla değil, doğrudan kastla öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle Esas Mahkemesinin mahkûmiyet hükmünün bozulmasını talep eder.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olayda kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinin bulunduğu ve S hakkında TCK'nın 87. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne istinaden mahkûmiyet hükmü kurulması gerektiği gerekçesiyle, Esas Mahkemesinin mahkûmiyet hükmünü bozar (30.11.2010, E. 2010/2565, K. 2010/7628).

Esas Mahkemesi, önceki kararında direnir.

Bunun üzerine dosyanın görüşüldüğü Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda, Yargıtay 1. CD'sinin bozma kararı doğrultusunda, kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinin gerçekleştiği yönünde içtihatla bulunulur (CGK, 5.6.2012, E. 2011/1-840, K. 2012/214).

Kanaatimizce, bu olayda Yargıtay 1. CD'sinin ve Ceza Genel Kurulu'nun kararları doğru değildir. S, 4 metre mesafeden maktulü hedef alarak silahı ile ateş etmiştir. Karara konu teşkil eden olayda, kaçmaya teşebbüs eden kişi hedef alınarak silahla ateş edilmeden de, durdurulması ve kimliğinin tespit edilmesi mümkündü. Bu itibarla, **Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkûmiyet hükmü ve direnme kararı hukuka uygundur.**

sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde yaralanması sonucunu doğuracak şekilde hedef itti haz edilerek silahla ateş edilebilmelidir. Çünkü, aksi takdirde, şüphelinin kim olduğunu tespit etme ve dolayısıyla, yakalanması imkanı olmayabilecektir. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda silah, kişinin ancak yaralanması suretiyle ve **her halde canlı olarak yakalanması amacıyla** kullanılabilir^{457,458}. Bu bakımdan, kişinin yakalanmasını sağlayacak ölçünün ötesinde yaralanması sonucunu doğuracak şekilde silah kullanılması halinde, **hukuka uygunluk sebebinin sınırının aşıldığını** kabul etmek gerekir.

Belirtmek gerekir ki, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 2.6.2007 tarihli ve 5681 sayılı Kanunla değiştirilen 16. maddesi hükmü hariç, mevzuatımızda kolluk görevlilerinin silah kullanma yetkisi düzenlenirken meşru müdafaa ile sair haller bakımından bir ayırım gözetilmemiştir. Bu nedenle, hukuk sistemimizde, çeşitli kanunlarda yer alan kolluk görevlilerinin silah kullanma yetkisine ilişkin düzenlemeler, çeşitli yönlerden yanlışlıklar içermektedir⁴⁵⁹.

1982 Anayasasının "yaşama hakkı"yla "vücut dokunulmazlığı"nı teminat altına alan 17. maddesinin dördüncü fıkrasında bu hak ve dokunulmazlığın istisnaları düzenlenmiştir. Yani, maddede zikredilen hallerde kişi yaşama hakkının veya vücut dokunulmazlığının varlığından bahsedemeyecektir. Söz konusu hükme göre, "... **bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi ... sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri**" hayat (yaşama) hakkının ihlâli olarak telakki edilemez! Bu hüküm, *tutuklu veya hükümlünün kaçmasını önlemek için silah kullanılmasına*

⁴⁵⁷ Nitekim, Bakanlar Kurulu'nun 7.4.1938 tarihli ve 2/8501 sayılı Kararı ile kabul edilen "Polis Vazife ve Salahiyet Nizamnamesi"nin (RG: 25 Nisan 1938/3890) 17. maddesinde, silah kullanma yetkisinin kullanılması halinde "... mümkün olduğu kadar suçlunun öldürülmekten ziyade yaralı olarak yakalanmasına dikkat edilmesi ... icabeder" ifadesine yer verilmiştir.

⁴⁵⁸ Hukuk dışı yollarla sınır geçişleri sırasında sınırı geçmek isteyen kişilerin geçişinin engellenmesi veya geçtikten sonra yakalanmalarını sağlamak amacıyla silah kullanılabilir. Ancak kaçak olarak sınırı geçmek isteyen veya geçen kişilerin öldürülmesi sonucunu doğuracak şekilde silah kullanılmasına hukuken izin verilemez.

Hukuk dışı yollarla sınırı geçmek isteyen kişilerin geçişini engellemek amacıyla, bu kişileri uyarmak amacıyla, salt korkutmaya yönelik olarak silah kullanılabilir. Keza, hukuk dışı yolla sınırın geçilmesi halinde, geçen kişilerin yakalanmasını sağlamak için silah kullanılabilir. Dikkat edilmelidir ki, hukuk dışı yollarla sınır geçişlerinde kişilerin kimliklerinin tespiti büyük bir önem taşımaktadır. Bu itibarla, bir saldırının veya saldırı tehlikesinin bulunmaması kaydıyla, silah kullanmanın kişileri öldürmek amacına yönelik olması hiçbir surette tasvip edilemez.

28 Aralık 2011 tarihinde, kaçakçılıkla iştigal ettikleri belirtilen 34 kişinin Uludere'de gece saatlerinde Irak sınırından ülkemize giriş yaparken Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bombalanmak suretiyle öldürülmesini bu çerçevede bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekir.

⁴⁵⁹ Bu itibarla, Yenisey, kolluk görevlilerinin "zor kullanma ve silah kullanma (yetkisi) bakımından Türk mevzuatının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği" yargısına varmaktadır (YENİSEY, Feridun: *Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi: Mukayeseli Hukuk, AİHM Kararları*, in: Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, İstanbul 2005, sh. 104).

cevaz veren bir kanunî düzenlemeye imkan tanımaktadır. Verilen cevaz, sadece soyut silah kullanmaya ilişkin olmayıp, **kaçan tutuklu veya hükümlünün** silah kullanmak suretiyle **öldürülmesini** de kapsamına almaktadır⁴⁶⁰.

Bu bakımdan sorunun, kolluk görevlilerinin silah kullanma yetkisi ile ilgili mevzuatımız hükümlerinin Anayasaya aykırılığından ziyade, **Anayasadaki söz konusu düzenlemenin insan haklarına ilişkin evrensel ilkelerle bağdaşmaması sorunu** olarak algılanması gerekir.

Çeşitli kanunlarda yer alan silah kullanma yetkisine ilişkin hükümlerin bu çerçevede bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

8.9.1971 tarihli ve 1481 sayılı "*Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun*"da kolluk görevlilerinin "*silah kullanma yetkisi*" ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir (m. 1 ve 2). Buna göre; 1. maddenin (B) bendinde belirtilen "*idam veya ağır hapis cezasını gerektiren suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sanık veya hükümlü olup da haklarında tevkif veya yakalama müzakeresi çıkarılan*" kişilerin "... teslim olması için yapılan (Teslim ol) ihtarından sonra, ... silah kullanılır" (m. 2, bent [a]).

Bu konuda "*silah kullanma yetkisi*" başlığını taşıyan 13.5.1971 tarihli ve 1402 sayılı "*Sıkıyönetim Kanunu*"nun 4. maddesinin ikinci fıkrası ile, 25.10.1983 tarihli ve 2935 sayılı "*Olağanüstü Hal Kanunu*"nun 23. maddesinin ikinci fıkrası emniyet görevlilerine daha açık bir yetki tanımaktadır. Bu iki Kanuna göre, "... güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi ... halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensupları doğrudan ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler".

Bu Kanunlara göre, "teslim ol" emrine riayet etmediği için kendisine ateş edilen kişinin belli bir suçtan dolayı şüpheli, sanık veya mahkûm olarak aranan bir kişi olması gerekmez. Bu düzenleme karşısında, güvenlik görevlisi, teslim olması için çağrıda bulunduğu ve fakat, bu çağrıya riayet etmeyen herhangi bir kişiye karşı "tereddütsüzce" ateş edebilecektir.

Hemen ifade etmemiz gerekir ki; bütün bu düzenlemelerde "*silah kullanma yetkisi*"nin kullanılması, kaçan kişinin kolluk ve sair güvenlik görevlilerine ya da sair herhangi bir şahsa saldırı, tecavüz teşebbüsünde bulunması şartına da bağlanmamıştır.

⁴⁶⁰ Anayasanın bu düzenlemesinde "**İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi**"nin "*Yaşama hakkı*" başlıklı 2. maddesi hükmü esas alınmıştır. Söz konusu Sözleşmenin 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yaşama hakkını güvence altına alan hükmü yer verildikten sonra, (2) numaralı paragrafta, "*hukuka uygun bir gözaltına alma kararını uygulama veya hukuka uygun olarak tutulan bir kimsenin kaçmasını önleme*", yaşama hakkının istisnaları arasında sayılmıştır (bent [b]). Dikkat edilmelidir ki, İHAS, *bu düzenlemesi itibarıyla* (!), salt kaçan bir kişiye karşı öldürülmesi sonucunu doğuracak şekilde silah kullanılmasına imkan vermektedir (İHAS, m. 2 hükmünün bu bağlamda değerlendirmesi için bkz. DÖNMEZER, Sulhi: *Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi ve İnsan Hakları*, in: *Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi*, İstanbul 2005, sh. 9 vd.).

"Silah kullanma yetkisi"ni düzenleyen bu maddelerde her ne kadar "güvenlik kuvvetlerinin meşru savunma durumuna düşmeleri hali"ne de ayrı bir ihtimal olarak yer verilmekte ise de; Kanunda açık bir hüküm olmasa bile, böyle bir durumda kolluk ve sair güvenlik görevlilerinin, meşru savunma halinde bulunmaları nedeniyle, beraatleri cihetine gitmek gerekir. Yani, yakalamak için takip ettikleri şüpheli, sanık veya mahkûmun silahlı veya silahsız saldırısına, tecavüzüne maruz kalan kolluk görevlilerinin bu saldırıyı etkisiz kılmak (defetmek) için silah ve sair bir vasıta ile saldırgana, mütecavize kuvvet kullanmaları halinde, hukuka uygun bir tutum içindedirler.

Kolluk görevlilerinin "silah kullanma yetkisi"ne ilişkin Yargıtay'ın birkaç önemli Kararını da bu meyanda zikretmek gereğini hissetmekteyiz:

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen bir mahkûmiyet kararının temyizi üzerine, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin verdiği 15.4.1987 t. ve 1285/1248 s. Kararı aynen şöyledir:

«Anarşinin yoğun olduğu tarihlerde, olay mahallinde silah atılması nedeniyle o bölgede devriye gezen her iki sanık polisin dahil olduğu ekibe, Necdet isimli şahsın şüpheli şahıslar olarak bildirdiği maktül ve yanındakilerin bulunduğu ... otoyola dur ihtarına rağmen süratle hareket edip uzaklaşması sırasında 15 metre kadar mesafeden her iki sanığın ateş etmeleri sonucu arabanın arkasındaki maktülün kafasından vurularak ölmesinde sanıkların eylemlerinin ... yasal savunma şartları altında işlendiğinin kabulü ... gerekir.»⁴⁶¹

Aynı şekilde, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 4.5.1987 t. ve 1-18/246 s. Kararında, yemek yiyip içki içtikten sonra ehliyetsiz oto kullanan "S.Y.nin, üç ayrı yerde polislerin üzerine otomobilini sürüp, çalınan düdüklere, fenerle verilen işaretlere ve hatta ikaz atışlarına aldırmayarak, gecenin ilerlemiş saatlerinde anarşik olayların yoğun olduğu bir bölgede (İstanbul, Ataköy ve Yeşilköy civarında) müteaddit «dur» emrine riayet etmeyip, haklarında her türlü şüpheyi uyandırdıktan sonra; ... polis memurlarının başka türlü durduramayacaklarını anladıkları otomobilin arka tekerleklerine ateş ederken, arka koltukta oturan bir kişiyi öldürmeleri olayında, (765 s. mülga) TCK. 49/1. maddesindeki (meşru savunmaya ilişkin) şartların gerçekleştiğini kabul" etmiştir⁴⁶²

Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen bir mahkûmiyet kararının temyizi üzerine, yine 1. Ceza Dairesi'nin verdiği 18.11.1987 t. ve 4125/4031 s. Kararda da aynı telakki hakim olmuştur:

«Hırsızlık suçundan aranan maktül Tahsin'in yakalanması bakımından Komiser Muavini Murtaza'nın komutasındaki Bekçi İlyas ve Polis Memur-

⁴⁶¹ YKD. Kasım 1987, sh.1703 vd. (1705).

⁴⁶² UYGUN, Mehmet/SAVAŞ, Vural/MOLLAMAHMUTOĞLU, Sadık: Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara 1987, sh. 9/10.

ları Fevzi ve Mahmut'dan oluşan ekip, adı geçen maktulü yakalamak üzere, Güroymak Bucağı'na gittikleri, Güroymak'a gelir gelmez cadde üzerinde rastladıkları maktul Tahsin'in, «dur» ihtarına rağmen kaçması ile Bekçi İlyas ve Polis Memuru Fevzi'nin kovaladıkları ve yakalanmasını kolaylaştırmak bakımından ihtar atışlarına rağmen maktulün bu ilk aşamada kaçmayı başardığı, ... ihtar atışlarını duyan Jandarma Erleri Ramazan, Sezai, Erol ve Cemal'in, Vahan'ın komutasında olay yerine gelmek üzere hareket ettikleri, arama sürerken Polis Memuru Mahmut tarafından maktulün yeniden görülmesi ile teslim ol emrine uymayan ve ihtar atışlarını umursamamaya kaçan maktule iki el ateş ettiği, bu arada olay yerine gelen Jandarma Erleri sanıklar Ramazan, Sezai, Erol ve Cemal'in de ateş etmeleri sonucu maktulün aldığı üç isabet sonucu öldüğü ... anlaşılmaktadır. Komiser Muavini Murtaza'nın komutasındaki Bekçi İlyas ve Polis Memurları Fevzi ve Mahmut'dan oluşan güvenlik ekibi, hırsızlık suçundan sanık ve firari maktul Tahsin'i yakalamak üzere görevlendirilmişlerdir. Bu itibarla verilen emri yerine getirmekle yükümlüdürler. Yasaya uygun olarak verilen bu emri yerine getirdikleri sırada kendi yetkileri sınırı içinde, yasal şekillere uygun olarak yapılan fiil ve hareketlerini meşru saymak gerekir.

... sanıkların takip sırasında «teslim ol» çağrısına uymayan ve ihtar atışlarına da aldırmamaya kaçan maktule karşı ... ateş etmelerini **yasal savunma** şartları dahilinde mütalâa etmek gerekir.

Bu oluşa göre, sanıklar hakkında (765 s. mülga) TCK'nın 49/2. maddesi uyarınca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.»⁴⁶³.

⁴⁶³ YKD. Şubat 1988, 273 vd. (274). Yargıtay, bir başka kararında da aynı ilginç gerekçelerle sanık hakkında beraat kararının verilmesi gerektiği görüşünü dermeyer etmiştir: "... Sanık (Asteğmen), ... firarî bir sanığın yakalanmasıyla görevlendirilmiş olup; bu görevin ifası için refakatinde bulunan jandarma erleri ile birlikte ... köyüne geldiklerinde, bir evin damından atlayan kişinin harmanlar arasında saklan(ması) ... üzerine; ... harmanlar arasında saklanan kişinin bulunup meydana çıkarılması için (ot harmanını ateşe vermiştir. Bu) ... suretle gizlenen kişinin yakalanmasını sağla(mıştır). -Yanan ekin sahibine zarar verme kastı ile hareket etme(yen) ... sanığın «infazı vazifeten zarurî bir emrin icrası» ile görevlendirilmesi, olayın anarşik hareketlerin yoğun olduğu bir yörede cereyan etmesi, harman yerinde gizlenen ve jandarma görevlilerinin takibine maruz kalan kişinin silahla karşı koyma ihtimali ... gözönünde tutulduğunda; sanığın beraatine karar verilmesi" gerekir (CGK., 2.2.1987, 8-553/31: UYGUN/SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, 1987, sh. 86/87).

Karara esas teşkil eden olayda zanlının yakalanması için silah kullanılmamış; ancak, zanlının saklandığı ekin harmanı ateşe verilmiş ve bu suretle zanlı yakalanmıştır. Hadisede, her ne kadar silah kullanma mevzu bahis değilse de; bir zanlının yakalanması amacıyla bir başkasının veya başkalarının malvarlığına karşı ika edilmiş bir zarar vardır. Kaçan zanlı, ot harmanları arasında saklanmıştır. Emniyet görevlilerinin (jandarmanın) zanlının ot yığınları arasından çıkması için önce başka yolları deneyip denemediği, denemişse hangi yolları denediği Ceza Genel Kurulu'nun kararının yayınlanan metninde zikredilmemiştir.

Kanaatimizce, zanlı kişinin ot yığınları arasından çıkmasını sağlamak için, şahıs(lar)a ait ot yığınının ateşe verilmesi her halde hukuken tecviz edilemez. Ot yığını içinde saklanan kişinin

Ancak, kolluk görevlilerinin engebeli bir arazide takip ettikleri şüpheli kişiye "dur" ihtarında bulunmalarına rağmen, silahı olmayan şüpheli kişiyi, kaçmaya devam etmesi üzerine, ateş ederek, öldürdükleri olaya ilişkin olarak, *Ceza Genel Kurulu'nun 2/3'ü geçen oy çokluğuyla verdiği 6.10.1986 t. ve 199/419 s. Kararında yukarıda bulunduğumuz izahatı kısmen pekiştiren açıklamalara yer verilmiştir:*

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 4. maddesinden bahisle; "sözü edilen bu hükümdeki «ateş etme yetkisi», «öldürme yetkisi» anlamına gelmez"⁴⁶⁴. "Sanığın, kaçan maktulü yakalamak kastıyla silah kullanması görevi gereğidir. Ancak, ölmeyecek noktalara yönelterek silah kullanması gerekirken; doğrudan doğruya maktulün kafasına ateş ederek vurup öldürmesi şeklindeki oluşta ... zaruretin tayin ettiği hudut tecavüz edilmiştir. -Oluşa ve açıklanan delillere göre sanıkta öldürme kastının bulunduğu anlaşılmadığından, eylemi (765 s. mülga) TCK. 452 ve 50. maddelerine temas eder nitelikte"dir"⁴⁶⁵.

Karar, kanaatimizce, kısmen doğrudur. Zira, meselâ ayaktan yaralamak suretiyle kaçan zanlı kişinin yakalanmasına yetecek ölçüde silah kullanılmasına müsaade edilmiş olduğu kabul edilecek olursa; bu maksatla silah kullanılması, kolluk görevlisi açısından bir hukuka uygunluk sebebi teşkil eder. Ancak, yakalamaya yetecek ölçüde silah kullanılmak istenirken, kaçan kişinin ağır yaralanması veya öldürülmesi halinde, bir hukuka uygunluk sebebinin sınırı gayrı iradî olarak aşılmış olacaktır. Bu durumda mesele, hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılmasına ilişkin genel prensipler çerçevesinde halledilmesi gerekirdi"⁴⁶⁶. Hal-

silahlı olabileceği hususundaki soyut ihtimale yer vermek suretiyle de, ot yığınının yakılması-na haklılık kazandırılmaz.

⁴⁶⁴ UYGUN/SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, 1987, sh. 14.

⁴⁶⁵ Aynı Karar: UYGUN/SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, 1987, sh. 15.

⁴⁶⁶ «... Jandarma birliğinde er olup, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa göre, mülki, adli ve askerî görevleri yapmakla mükellef bulunan sanığın, olay gecesini, çavuş M komutasında er D ile birlikte ilçe merkezinde saat 21.00-23.00 iç hizmet devriye görevi yaptığı; bu görevinin gereği ve Sıkıyönetim Komutanlığının "Şehrin içinde umumî yerlerde ve şehrin giriş ve çıkışında tesis edilen yol kapamalarında mutlaka kimlik kontrolü yapılacaktır. Şüpheli görülenler gerekli tahkikat yapıldıktan sonra bırakılacaktır" biçimindeki emri uyarınca kahveleri kontrol etmek üzere giderlerken, ... Köyü yolundan bir traktörün ilçe merkezine doğru gelmekte olduğunu gördükleri; traktörün cezaevi civarında yanlarından geçtiği sırada römorkunda odun yüklü olduğunu görünce, odunun kaçak olduğu düşüncesiyle "dur" ihtarı verdikleri; bu ihtar alan traktör sürücüsü kaçak orman emvali nakletmek suçunun sanığı durumunda bulunan maktul K'nın traktörünü durdurmayarak aracını daha süratle sürerek uzaklaştığı ve devriye ekibinin sözlü ve düdüklü ihtarlarına rağmen durmayarak kaçmaya başladığı; bunun üzerine devriye erlerinin maktulü yakalamak amacıyla traktörün arkasından 70 metre kadar koştukları; ancak yakalayamadıkları; bunun üzerine aralarında en süratli koşan sanığın, traktörün arkasından koşup yetişerek traktörün motor kaportasına eliyle vurmak suretiyle durmasını bir kez daha ihtar etmesine rağmen, maktulün direksiyon kırıp kaçması üzerine, bütün çabalarına rağmen durdurmaya muvaffak olamayınca, **yaralamak suretiyle durdurmayı sağlamak amacıyla** hamili bulunduğu tüfekle bir el ateş ettiği, **sırttan girip göğüstten çıkan kurşunun ölümüne neden olduğu** anlaşılmıştır.

... (S)anığın sözlü ve düdüklü ihtarlarına rağmen durmayıp direksiyon kırarak kaçan maktulü yaralamak suretiyle durdurmak amacıyla atılan tek kurşun, gecenin karanlığında tesadüfen sanığın hayati önemli haiz bölgesine isabetle ölümü(ne sebep olmuştur). Ancak bu amaca kavuşmak isteyen ve traktöre ulaşip kaportasını yumruklayan **sanığın, traktörün önüne geçip maktulün sağına-soluna ve hayati önemi haiz bulunmayan bölgelerine, örneğin ayaklarına ateş edip onu durdurması mümkün iken, böyle yapmayarak arkasından ateş edip öl(ümüne sebep olmasına) göre, zaruret sınırını aşmak suretiyle öldürmek suçunu işlemiştir.**»: CGK, 21.2.1983, 429-66 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 676/677).

Ancak, Yargıtay pek çok olayda, sınırın aşılmış olmasına rağmen, kanunun hükmünü icra hukuka uygunluk sebebinin varlığından bahisle beraat kararı verilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir:

«... (T)eröristlere yataklık yaptığı ihbarı (üzerine, öğretmen olan) M, ... soruşturma sırasında ... sığınak ve mağaraları göstermek için götürüldüğünde, ağaçlı ve engebeli yerde ... kaçmaya başla(mıştır. Kendisine) “dur” ihtar(ında bulunulmuş), önce havaya ateş açıl(mış ve) kaçmaya devam etmesi üzerine, serbest atış yapılmıştır. (M.) bu ateşle başından, sırtından ve bacağından vurularak öl(müştür.)

(Mezkûr olayda;) 1402 sayılı Kanunun 4. maddesi ile, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 39. maddesi ve **TCK'nın 49/1. maddesinin** dikkate alınmadan; (sanıkların) TCK'nın 243/1. maddesi» hükmüne istinaden mahkum edilmesi hukuka aykırıdır: 1. CD, 17.11.1993, 1396/2390 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 654).

«Çevik Kuvvet Polisi olarak görev yapan sanık F'nin ... bir otunun hızla yaklaştığını gördüğünde ... ellerini havaya kaldırarak yavaşlayıp durmasını temine çalıştığı; ancak oto sürücüsünün yavaşlamadığını ve hızını da artırarak üzerine geldiğini görünce, kendisini kenara atıp silahını ikaz niteliğinde olmak üzere havaya tevcih ile birkaç defa ateşlediği; otunun ilerdeki polis barikatını da geçtiğini gördüğünde otunun tekerleklerine doğru atışlarını sürdürerek durdurabilmeyi amaçladığı, balistik incelemeye göre diğer polislerin 41, sanığın ise 13 el ateş etmesine rağmen maktul sürücünün durdurulabilmesinin mümkün olmadığı; sanıktan vaki atışlardan bir tanesinin otunun arka camından seyirle maktule isabet ederek ölümüne sebebiyet verdiği (olayda);

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16. maddesinin F ve H fıkralarına uygun şekilde ve yetki hudutlarını aşmaz düzeyde silah kullandığı anlaşılan sanığın 12 el ateş etmesine ve bu atışlarını muhataba isabet ettirmeyen bir titizlikle yapmış olmasına karşın onun durdurulmasını temin edemediği ahvalde; tek bir mermi ile yaralamasında aşırılıktan söz edilemeyeceği; 12 merminin ikaz mahiyetinde atılmasının da sanık lehine yorumlanmak yerine aleyhte değerlendirilerek zaruret sınırını aşmak mahiyetinde kabul **edilmemesi** gerektiği; bu ahvalde sanık polis memurunun gerek içinde bulundukları teyakkuz hali ve gerekse maktulün ısrarlı kaçışıyla yarattığı kuşku ortamında silahını kullanmasının, **TCK'nın 49/1. maddesinde tanımını bulan “yasal görevi icra” niteliğini aşmadığı sabit iken; ... TCK'nın 50. maddesi mucibince mahkûmiyet hükmü tesisi» doğru değildir:** 1. CD, 2.11.1993, 2053/2196 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 654/655).

«Olay gecesi saat 22 sıralarında ... adlı şahsın ... Polis Karakoluna telefon ederek ... plaka numaralı ... marka otomobilin ... benzin istasyonuna geldiği, bu arabada bulunan kişilerin silah çekerek (kendisine) hakaretlerde bulunduğunu ve ... istikametine doğru kaçtıklarını ihbar (etmesi üzerine;) sanığın takibe geçilmesi emri alarak o istikamete gidip, ... aracı yakın mesafeden takibe başladığı; durması için çeşitli şekillerde yapılan ikazlara uymadığı ve başka şekilde durdurulamayacağını anladığı için, ... araca doğru bir el ateş ettiği; rasgele yapılan bu atışla her iki araç da hareket halinde olduğu için çıkan kurşunun tesadüfen (takip edilen) araçta bulunan A'ya isabet ederek **ölümüne sebep olduğu** ... olayda; polis görevlisi olan sanığın silah kullanma şartlarının oluşması nedeniyle, fiilin TCK'nın **49/1. maddesi** şartlarında değerlendirilmesi ve fiilin aşırılığa kaçmadığının kabulünde zorunluluk bulunduğu halde; yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.»: 1. CD, 18.10.1993, 1551/1982 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 657).

buki Ceza Genel Kurulu, karara konu teşkil eden olayda 765 s. mülga TCK'nın bir netice sebebiyle ağırlaşmış suç halini düzenleyen 452. maddesinin uygulanmasını uygun görmüştür⁴⁶⁷. Bu görüşe iştirak etmemekteyiz. Çünkü, söz konusu

«... Emniyetinde görevli gece bekçisi ol(an sanık N'nin) ölen polis memuru G ve polis memuru H ile birlikte, hırsızlık yapan M'yi yakalamak için peşine düştükleri; G'nin M'ye “dur” ihtarında bulunup arkasından havaya silahı ile ateş ettiği; buna rağmen M'nin kaçmaya devam edip oradaki bir evin çatısına çıktığı; arkadaşından (G'nin) de çatıya tırmandığı, bu sırada çıkmaz sokak içerisinde beklemekte olan sanığın, duvardan çatıya tırmanan kişinin M olduğunu sanarak gece karanlığında bir el ateş ettiği, bu atış sonucu G'nin başından yaralanarak öldüğü (olayda); ... sanığın 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16/E maddesinin verdiği yetkiye dayanarak silah kullandığı, en iyi eğitilmiş bir atıcının bile gece karanlığında hareket halinde bir şahsı istediği bölgeden yaralayamayacağı da gözönünde tutulduğunda, sanığa TCK'nın 49/1. maddesinin uygulanmasında zorunluluk bulunduğu halde yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırıdır.» 1. CD, 6.12.1989, 3495/3477 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 661/662).

⁴⁶⁷ «Aksaray Kaymakamı ve Belediye Başkanının başkanlığında oluşan bir heyetin ... Helvadere kasabasına geldikleri ve burada gerekli işleri yapıp dönecekleri sırada kadın ve çocuklardan oluşan bir grup tarafından taşla tutuldukları, önceleri az olan kalabalığın giderek artması, vasıtalarının tahrip edilmesi ve beraberlerindeki güvenlik kuvvetlerinin yetersiz kalması üzerine Belediye binasına sığındıkları; ... Kaymakamın ... takviye kuvvet istediği; bir süre sonra gelen takviye kuvvetle kalabalığın havaya ateş edilerek dağıldığı; bundan sonra kaymakamın sözlü emri üzerine olayın elebaşılarının takip ve yakalanmaları için 2-3 kişilik timler oluşturulduğu; bu arada sanık Polis memuru A'nın da polis memuru D ve Jandarma eri Y ile bir ekip oluşturularak görevlendirildikleri; en önde sanık A, onun arkasında 15-20 metre mesafede D ve bir o kadar mesafede arkada Y olacak şekilde engebeli arazide kaçanları takip ettikleri, bu sırada sanığın önünde kaçan maktul R'ye “dur” ihtarında bulunduğu; ancak maktulün bunu dinlemeyip kaçmaya devam etmesi üzerine elindeki (akrep) tabir edilen otomatik silahla bir el ateş ettiği; yine durmasına üzerine ikinci kez ateşlediğinde arkadan başından vurup öldürdüğü ... (anlaşılmıştır).

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasında; silah kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin “teslim ol” emrine uyulmaması halinde, güvenlik kuvveti mensuplarına **doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilme yetkisi** verilmiştir. Bu yetkinin kapsam ve sınırlarını belirlemek gerekir. Sözü edilen bu hükümdeki “ateş etme yetkisi”, “**öldürme yetkisi**” anlamına gelmez.

Anılan Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasında sözü edilen yetki, aynı maddenin 1. fıkrasından kaynaklanmaktadır. 1. fıkra “görevlilerin ... Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullanma yetkisini haiz... oldukları” hüküm altına alınmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Silah kullanılmasını gerektiren halleri ile ilgili 87. maddesinin 3. bendinde, silah kullanma tarzı “... önce ayağa, devamı halinde hedef gözetilmeksizin ...” biçiminde özetlenecek şekilde açıklanmıştır.

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16. maddesinde, polisin silah kullanmaya yetkili olduğu haller belirtilmiş, bu yetkinin kullanılma biçimi de Polis Vazife ve Selahiyet Nizamnamesinin 17. maddesinde “... polis için silah kullanmak selahiyetinin kabul edildiği hallerde, silah kullanılması, silahı kullanmaktan başka çare bulunmadığı hallere münhasırdır. Bu takdirde mümkün olduğu kadar suçlunun öldürülmekten ziyade yaralanmasına dikkat edilmesi icap eder...” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinin 270. maddesinde, silah kullanmaktan maksadın öldürmeyi istihdaf etmeyip, sadece vazifenin yerine getirilmesini mümkün kılacak hale hasderildiği ve bunun için silahın lüzumu halinde kullanılmasının zorunlu olduğu, aynı Nizamnamenin 271. maddesinde açıklanmıştır.

452. maddenin uygulanabilmesi için önce hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş olan bir kasten “müessir fiil” (yaralama) suçunun işlenmiş olması gerekir. Ancak hukuka aykırı olarak işlenen kasten “müessir fiil” (yaralama) neticesinde kişinin ölmesi halinde, 452. madde uygulanabilecektir. Bu itibarla, kaçan zanlının yakalanmasını sağlamaya yönelik olarak silah kullanmaya ilişkin "hukuka uygunluk sebebi"nin sınırının "gayrı iradî olarak aşıldığı" kabul edilen olayda 452. maddenin uygulama yeri yoktur.

Bütün bu kararlara konu teşkil eden olaylarda -kararlardan anlaşıldığı üzere- kaçan kişilerden kaynaklanan bir saldırı hali mevcut değildir⁴⁶⁸. Bir tecavüzün

Görülüyor ki; ... 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 4. maddesi yukarıda sözü edilen kanunların belirtilen maddelerini ortadan kaldırmadığı gibi, birinci fıkrasında, güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisini, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda, Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde silah kullanmayı gerektiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku haline bağlamak suretiyle bu hükümlerin yürürlüğünü teyit etmektedir.

Sanığın, TCK'nın 49/1. maddesi hükmünü icra ederken, aynı Kanun 50. maddesi hükmünü de gözönünde bulundurması ve buna uyması gerekir. Zira TCK'nın 49. maddesindeki şartlar 50. madde ile sınırlandırılmıştır.

Sanığın, kaçan maktulü yakalamak kastıyla silah kullanması görevi gereğidir. Ancak ölmeyecek noktalara yönelerek silah kullanması gerekirken doğrudan doğruya maktulün kafasına ateş ederek vurup öldürmesi şeklindeki oluştta yukarıda açıklanan kanun hükümlerine uyulmamış ve zaruretin tayin ettiği hudut tecavüz edilmiştir.

... (S)anıkta öldürme kastının bulunduğu anlaşılmadığından; fiili **TCK'nın 452. ve 50. maddelerine** temas eder nitelikte görülmüştür.»: CGK, 6.10.1986, 199/419 (Savaş/Mollamahmut-oğlu I, sh. 669/670); aynı mealde CGK, 26.4.1982, 42/164 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 679/680).

«11.9.1981 gün ve 2524 sayılı yasaya dayanılarak çıkarılan “Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik”in 3. ve 60. maddeleri gereğince *Genelkurmay Başkanlığı*, Anıtkabire ilişkin her türlü hizmeti yapmakla ve *Anıtkabiri “hırsızlığa, sabotaj, baskın, yangın ve tahriplere karşı korumakla” görevlidir.*

Olay günü, Anıtkabir’in Gençlik caddesine bakan tarafında, 1-5 nolu nöbetçi kulübeleri arasında devriye nöbeti tutan sanı(k, bir şahsın) duvardan atlamak suretiyle Anıtkabir bahçesine girip Mozoleye doğru koştuğunu görünce, görevi gereği (onu) kovalamaya başla(mıştır. Kendisine) yetiştiği sırada yerden aldığı taşı sanığa fırlatan (şahsın) sanığı yaralayarak yere düşür(müş) ve ikisi bir süre boğuş(muşlardır). Sanı(k, elinden kurtulmayı başaran maktulün yeniden koşmaya başla(ması üzerine,) “dur” ihtarıyla havaya ikaz atışı yap(mış); maktul buna rağmen durmayınca hedef gözeterek yaptığı ateş sonucu ağır şekilde yaralan(mış ve) bir süre sonra öl(müştür). Sanığın öldürme kastıyla ateş ettiği kesinlikle belirlenmemiştir. Merminin maktulün vücuduna giriş çıkış yerleri de gözönünde tutularak, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 87. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerin gerçekleşmesi nedeniyle silah kullanma yetkisini kullanan sanığın, zaruretin tayin ettiği yetkiyi aştığının kabulü ile TCK'nın **452/1., 50, 59/2. maddelerinin** uygulanması suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesinde zorunluluk bulun»maktadır: 1. CD, 13.3.1991, 509/700 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 685/686).

⁴⁶⁸ Eğer bir saldırı hali mevcutsa, artık sorunu *meşru savunma* hükümleri çerçevesinde çözümlemek gerekir. Ancak, bir olayda, dövülerek zorla silahı elinden alınmağa kalkışılması üzerine ateş eden güvenlik görevlisinin fiili, Yargıtay tarafından “*görevin yerine getirilmesi*” olarak kabul edilmiştir: 1. CD. 28.10.1993, 2106/2160 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 655/656.). Ayrıca bkz. 1. CD. 18.11.1987, 4126/4031 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 662/663.).

bahis konusu olmadığı bu durumlarda, meşru müdafanın (meşru savunma) varlığını kabul etmek, hukuken mümkün değildir.

Kararlarda "anarşinin yoğun olduğu" yer ve zamanlar gibi gerekçelere yer verilmektedir. Bu tür gerekçeler, muğlaklık, belirsizlik taşıdıkları için, bir Hukuk Devletinde kabul edilemezler.

Bazı kararlarda kabul edilenin aksine; kolluk görevlilerinin "acemiliği"ne de bir gerekçe olarak dayanılmaz. Şayet bir acemilik söz konusuysa; bu acemilik, işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususunda değil, ancak failin kusurluluk durumu üzerinde etkili olabilir.

Kararlarda dayanan bir diğer gerekçe de, "yetkili merciin emrini ifa dolayısıyla bir hukuka uygunluk sebebi"nin mevcudiyetidir.

Söz konusu kararlarda "yerine getirilmesi mecburî olan" bir emirden bahsediliyorsa; bu emir, kaçan şüpheli, sanık veya mahkûmun yakalanmasına ilişkin olabilir. Yoksa, kaçan şüpheli, sanık veya mahkûmun yakalanmasını sağlamak amacıyla silah kullanmaya ilişkin bir emrin varlığından hiçbir kararda söz edilmemektedir. Bu itibarla, kaçan şüpheli, sanık veya mahkûmun yakalanmasını sağlamaya yönelik silah kullanılmasını "hukuki" addetmek için "infazı vazifeten zarurî bir emir"in varlığına dayanmak ve bu suretle kamu görevlilerinin "yasal savunma" şartları içinde hareket ettiğini iddia etmek, hukuken kabul edilemez⁴⁶⁹.

Ancak belirtmek gerekir ki, **21.3.2007** tarihli ve **5607** sayılı (yeni) "*Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu*"nun "*Silah kullanma yetkisi*" başlıklı 22. maddesinde bu eleştirilerimiz büyük ölçüde dikkate alınarak bir düzenleme yapılmıştır. Bu madde hükmüne göre; «*Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen kişiye "dur" uyarısında bulunulmasına rağmen bu uyarıya uymaması halinde, havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir. Ancak silahla karşılığa yeltenilmesi ve sair surette meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırtıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan hedefe ateş edebilir.*» (fıkra 1)⁴⁷⁰.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, 3713 s. Terörle Mücadele Kanunu'na 1996 yılında 4178 s. Kanunla eklenen Ek 2. maddeyi, Anayasanın 17. maddesine

⁴⁶⁹ Bu itibarla, *Bayraktar*'ın, kolluk görevlilerinin silah kullanma yetkisi sonucunda meydana gelen ölüm vakalarıyla ilgili olarak Yargıtay'ın "*kanunu hayli dar yorumladığı ve haklı savunma koşullarını tam olarak uygulamadığı*" yönündeki "tespit"i, gerçeklerle bağdaşmamaktadır (BAYRAKTAR, Köksal: *Kolluğun Silah Kullanma Yetkisinin Yasal Dayanakları*, in: *Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi*, İstanbul 2005, sh. 38).

⁴⁷⁰ Keza, görevlilerce durdurulması istendiği halde, «*Görevlilerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden her nevi deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama, mors ve benzeri işaretlerle durması ihtar olunur. Bu ihtara uymayan deniz araçlarına uyarı mahiyetinde ateş edilir. Buna da uymayıp kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya zorlayacak şekilde üzerine ateş edilir.*» (fıkra 2).

aykırı bularak iptal etmiştir⁴⁷¹. Söz konusu Ek madde 2 hükmü şu şekilde idi:

“Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine itaat edilmeyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk kuvveti görevlileri, failleri etkisiz kılmak amacıyla doğruca ve duraksamadan hedefe karşı ateşli silah kullanmaya yetkilidirler.”

Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararının gerekçesi özet olarak şu şekildedir:

«Ek Madde 2'de, terör örgütlerine karşı yapılacak operasyonlarda, kolluk kuvveti görevlilerinin silah kullanmaları, teslim ol emrine itaat edilmeyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi koşuluna bağlanmıştır. Bu koşulun gerçekleşmesi durumunda görevliler failleri etkisiz kılmak amacıyla, doğruca ve duraksamadan, hedefe karşı ateşli silah kullanabileceklerdir.

Maddede "teslim ol emrine itaat edilmemesi" ve "silah kullanmaya teşebbüs edilmesi" durumunda, kademeli olarak etkisiz kılma yöntemleri belirtilmeden, kolluk kuvvetlerine son çare olarak başvurulması gereken ateşli silah kullanma yetkisi verilmiştir.

Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrasında, "herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir". Son fıkrasında da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesine koşut olarak "mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri birinci fıkra hükmü dışındadır" denilmektedir.

Bu maddeyle güvence altına alınan yaşama hakkını korumak için devlet her türlü önlemi almak yükümlülüğündedir. Yasa ile ancak zorunlu durumlarda silah kullanma yetkisi verilebilir. Silah kullanmaya yetki verilebilmesi için son fıkrada sayılan durumlarda yetkililerin silah kullanma dışında başka olanaklarının bulunmaması gerekir.

Kuralda faillerin sadece "silah" kullanmaya teşebbüslerinden söz edilirken kolluk kuvveti görevlilerinin hedefe karşı "ateşli silah" kullanmalarından söz edilmiş; böylece **faillerin kullanmaya teşebbüs ettikleri silahın ateşli silah olup olmadığına bakılmaksızın ve başka türlü etki-**

⁴⁷¹ Anayasa Mahkemesinin 6.1.1999 t. ve E: 1996/68, K: 1999/1 s. Kararı (RG: 19 Ocak 2001 / 24292, sh. 19 vd.).

siz hale getirilmeleri olanağı gözetilmeksizin küçük bir müdahale ile önlenebilecek olaylarda dahi görevlilere ateşli silahlar kullanma yetkisi verilmiştir.

Buna göre, dava konusu kuraldaki **teslim ol emrine uyulmaması ve silah kullanmaya teşebbüs edilmesi, görevlilerin her zaman doğruca ve duraksamadan hedefe karşı ateşli silah kullanmalarını zorunlu kılacak nitelikte bir durum değildir.** Kimi olaylarda faillerin, can güvenliğini daha az tehlikeye sokan yöntemlerle de etkisiz hale getirilmeleri olanaklı olabilir. Olayların özelliğine göre, bu yöntemlere başvurulmaksızın doğruca ve duraksamadan hedefe karşı "ateşli silah" kullanılması yaşama hakkının zedelenmesi sonucunu doğurur.»

Terörle Mücadele Kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Ek 2. maddesi, 29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir (m. 16):

*“Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda **"teslim ol" emrine itaat edilmemesi veya silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde** kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabilecek ölçü ve orantıda, doğrudan ve duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya yetkilidirler.”*

Söz konusu Ek 2. madde metni, 5532 s. Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısında şu şekilde idi:

*“EK MADDE 2- Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda **"teslim ol" emrine itaat edilmeyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde** kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabilecek ölçü ve orantıda, duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya yetkilidirler.”*

Ancak, 5532 s. Kanunun TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında, söz konusu madde hükmünde, (o tarihte) Kara Kuvvetleri Komutanı (olan) Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT'ın talebi doğrultusunda TBMM Adalet Komisyonunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle, madde metnine, “*teslim ol' emrine itaat edilmeyerek*” ibaresinden sonra gelmek üzere, “*veya*” ibaresi ve keza, “*duraksamadan*” ibaresinden önce gelmek üzere, “*doğrudan ve*” ibaresi eklenmiştir.

TBMM Adalet Komisyonunun 26.6.2006 tarihli ve Esas No: 1/1194, Karar No: 106 sayılı Raporunda bu değişikliğin “**terörle mücadelede kolluk kuvvetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla**” yapıldığı belirtilmiştir⁴⁷²:

Tasarının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında, madde metnindeki “*teslim ol' emrine itaat edilmeyerek*” ibaresi, “*teslim ol' emrine itaat edilmemesi*” olarak değiştirilmiştir ve madde bu şekliyle kanunlaşmıştır.

Terörle Mücadele Kanununun bu yeni düzenlemesine göre, kolluk görevlilerinin silah kullanılabilmesi için, “*terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyon-*

⁴⁷² Gerekeçe metni için bkz. TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Sıra Sayısı: 1222.

larda” örgüt mensuplarına önce, “*teslim ol*” şeklinde bir emirde bulunulacak ve kişi bu emre uygun hareket etmeyip kaçmaya devam edecek ya da silah kullanmaya teşebbüs edecektir.

Madde metninde geçen “*terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda*” ibaresini, terör örgütünün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olmak ya da bu örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlemek dolayısıyla şüpheli, sanık veya hükümlü bulunan kişilerin **yakalanmalarını sağlamak amacıyla yönelik girişimler** olarak anlamak gerekir.

Dikkat edilmelidir ki, bu düzenlemeye göre, **kolluk görevlilerince silah kullanılabilmesi için, terör örgütü mensuplarının “teslim ol” emrine itaat etmeleri yeterlidir.** Bunun için, örgüt mensuplarının **ayrıca** silah kullanmaya teşebbüs etmeleri ve hatta, **silahlı olmaları bile aranmamıştır.**

Bu bakımdan, söz konusu düzenleme, örneğin derede yıkanmakta olan örgüt mensuplarının “teslim ol” ihtarı karşısında çıplak vaziyette kaçmaya teşebbüs etmeleri halinde de kolluk görevlilerine silah kullanma yetkisi vermektedir.

Bu düzenlemede, **terör örgütü mensuplarının silah kullanmaya teşebbüs etmesi**, kolluk görevlilerince silah kullanılabilmesi bakımından ikinci bir ihtimal olarak kabul edilmiştir. Aslında bu durum, TCK’nın 25. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen **meşru savunmanın** koşullarından birini oluşturan **saldırı** halini ifade etmektedir.

Halbuki 5532 sayılı Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısında, örgüt mensuplarının “teslim ol” emrine itaat etmeyerek **silah kullanmaya teşebbüs etmeleri halinde**, kolluk görevlilerine silah kullanma yetkisi verilmişti. Bunun için aranan koşullar sırasıyla şunlardı:

- 1) terör örgütünün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olmak ya da bu örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlemek dolayısıyla şüpheli, sanık veya hükümlü bulunan kişilerin **yakalanmalarını sağlamak amacıyla yönelik bir “operasyon”**un varlığı gereklidir.
- 2) Bu operasyon sırasında, kolluk görevlileri tarafından örgüt mensubu kişilere “teslim ol” çağrısında bulunulması gerekir.
- 3) Örgüt mensuplarının, “teslim ol” çağrısına uymayarak, **silah kullanmaya teşebbüs etmeleri** (ve dolayısıyla, **silahlı olmaları**) gerekir.

Başka bir deyişle, 5532 sayılı Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısına göre, yakalanmalarına yönelik “operasyon” sırasında örgüt mensupları silahlı değillerse; kolluk görevlileri bu kişileri hedef alarak silah kullanamayacaklardı.

Bu yönüyle, 5532 s. Kanunla yeniden düzenlenen Ek 2. madde hükmü, 29.08.1996 tarihli ve 4178 sayılı Kanunla (m. 3), Terörle Mücadele Kanununa eklenen ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükme göre insan hakları bakımından daha sorunlu bir hal almıştır⁴⁷³.

⁴⁷³ Bu hususta ayrıca bkz: ÖZGENÇ, İzzet: *Terörle Mücadele Kanunu*, Ankara, 2006, sh. 104 vd.

Ayrıca, 5532 s. Kanunla yeniden düzenlenen Ek 2. madde hükmünde, yakalanmalarını sağlamak amacıyla silah kullanılabilmesi için, örgüt mensuplarının kaçmalarına engel olmak bakımından başka çare bulunmaması şartı da aranmamıştır. Ancak, 4178 s. Kanunla Terörle Mücadele Kanununa eklenen Ek 2. madde hükmünden farklı olarak; yeni düzenlemede, silahın **“tehlikeyi etkisiz kılabilir ölçü ve orantıda”** kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Fakat, bu orantının yanı sıra, silahın **“doğrudan ve duraksamadan hedefe karşı”** kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Çelişkili gibi gözükse de bu düzenleme karşısında yukarıda sözünü ettiğimiz iki ihtimalde göre sorunu açıklığa kavuşturmak gerekir.

Birinci ihtimal, terör örgütü mensuplarının **“teslim ol” emrine itaat etmemesi** dolayısıyla kolluk görevlilerince silah kullanılmasıdır. Bu ihtimalde, örgüt mensuplarının **yakalanmalarını sağlayacak ölçü ve orantıda** silah kullanılabilir. Madde metninde silahın **“doğrudan ve duraksamadan hedefe karşı”** kullanılabileceği belirtildiğine göre; bu düzenleme, “teslim ol” veya “dur” ihtarı karşısında kaçan örgüt mensuplarının **yakalanmalarını sağlayacak derecede yararlanmalarını sonuçlayacak şekilde** silah kullanılmasına izin vermektedir.

İkinci ihtimal, terör örgütü mensuplarının **silah kullanmaya teşebbüs etmesi** dolayısıyla kolluk görevlilerince silah kullanılmasıdır. Bu ihtimalde, sorunu **meşru savunma** hükümleri çerçevesinde değerlendirmek ve dolayısıyla, savunma amacıyla gerçekleştirilen fiilin **saldırının etkisiz kılacak ölçü ve oranda** olması gerekmektedir⁴⁷⁴.

Amaç ve orantı bu suretle belirlendikten sonra; kolluk görevlileri tarafından kullanılan silahın ateşli silah olup olmasının bir önemi kalmamaktadır.

Ekskurs 2. Görevin Yerine Getirilmesi Hukuka Uygunluk Sebebi Bağlamında Müdafilik Görevinin Kapsam ve Sınırları⁴⁷⁵

I. İddia ve savunma hakkı, 1961 Anayasası’nın 31 maddesinde olduğu gibi, 1982 Anayasası’nın 36. maddesinde düzenlenmiştir:

“Herkes meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak, iddia ve savunma hakkına sahiptir.”^{476,477}

⁴⁷⁴ Anayasa Mahkemesinin **19.10.2021** tarihli ve 2016/9350 Bireysel Başvuru kararındaki değerlendirmeler, bu açıklamalarımızla paralellik arz etmektedir.

⁴⁷⁵ Kitabımızın üçüncü basısında bu başlık altında yer alan açıklamalar, muvafakatıma binaen aynen iktibas edilerek, GÖKCAN, Hasan Tahsin: *Açıklamalı Avukatlık Yasası, Avukatların Görev Suçları, Özel Soruşturma Usulü, Hukuki Sorumluluk*, 2. bası, Ankara, 2009, sh. 278 vd’nde yayımlanmıştır.

⁴⁷⁶ 1961 Anayasasının 31. maddesinde “... meşru bütün vasıta ve yollardan ...” ibaresi yer almaktaydı. 1982 Anayasasında «“bütün” sözcüğüyle yapılan vurgulamanın kaldırılması, maddenin anlamını değiştirmemiştir. ... “meşru vasıta ve yollardan” ibaresi, kuşkusuz “meşru bü-

Anayasa’da sadece savunma hakkı değil, aynı zamanda iddia hakkı da güvence altına alınmıştır. İddia ve savunma hakkı, iki ayrı hak niteliği taşımakla birlikte, birbiriyle olan sıkı ilişki nedeniyle birlikte mütalaa edilmektedir.

Savunma hakkının dayanağı, *insanın esasen masum oluşudur*. Zira, kişi, bu hakkın kullanılmasıyla kendisine yöneltilen bir haksızlık gerçekleştirdiği ve dolayısıyla başkalarını mağdur ettiği hususundaki iddialara karşı kendisini savunma imkanı bulmaktadır.

Suç isnadıyla karşı karşıya kalan kişi savunma hakkını bizzat kendisi kullanabileceği gibi, müdafî sıfatıyla bir avukatın yardımından da yararlanabilir. **Müdafî**, Ceza Muhakemesi Kanununa göre, “*şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı ifade eder*” (m. 2, f. 1, bent c). İster suç isnadıyla karşı karşıya kalan kişinin kendisi belirlemiş olsun, ister mahkeme veya C. savcısının talebi üzerine baro tarafından görevlendirilmiş olsun, avukat, müdafilik görevini yaparken, kendisine birtakım yükümlülükler yüklenmektedir.

Bu yükümlülüklerin başında avukatın **sır saklama yükümlülüğü** gelmektedir. Avukat, vekâlet ilişkisi içinde bulunduğu ya da müdafiliğini üstlendiği kişiye ilişkin bazı bilgilere, bu hukuki ilişkinin gereği olarak vakıf olmaktadır. Bu bağlamda avukat, müdafiliğini üstlendiği kişinin soruşturma veya kovuşturma konusu suçu ya da sair bir suç işlediği hususunda bir bilgiye ulaşabilir. Müdafilik görevinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için, bu görevi üstlenen avukatın bu suçlarla ilgili bildirim yükümlülüğünden söz edilemez. Başka bir ifadeyle, avukat, müdafiliğini üstlendiği kişinin soruşturma veya kovuşturma konusu suçu ya da sair bir suç işlediğini öğrense bile, sır saklama yükümlülüğünün gereği olarak, suçu takibe yetkili makamlara bu suçlarla ilgili bildirimde bulunamaz.

Vekil veya müdafî olarak görevlendirilen avukat, sır saklama yükümlülüğü ile bağlantılı olarak, müvekkili veya müdafiliğini üstlendiği kişi aleyhine **tanıklık yapmama yükümlülüğü** altındadır. Bu nedenle, klasik anlayış, sözkonusu du-

tün vasıta ve yolları” kapsar.»: Anayasa Mahkemesi, 31.3.1992, E.1991/18, K.1992/20, AMKD, Sayı 28, Cilt 1, Ankara 1993, s. 232 vd. [295]).

1961 Anayasasına ilişkin Tasarı metninde “*Herkes, bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.*” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmişti. Ancak, Temsilciler Meclisindeki görüşmeler sonucunda, Anayasa metninde yargı mercileri önündeki savunma hakkının “*meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle*” kullanılabileceği ifadesine yer verilmiştir. Savunma hakkına bu ifadeyle getirilen sınırlama, söz konusu hakkın niteliğinden kaynaklanmaktadır.

⁴⁷⁷ Anayasa’da, iddia ve savunma hakkı “*yargı mercileri*”ne inhisar edilmiştir. Kişi idarî makamlar nezdinde de iddiada bulunabilir. Keza, kişi kendini kolluk ve disiplin kurulu gibi idari makamlar önünde de savunma ihtiyacı duyabilir. Bu itibarla, savunma hakkına Anayasayla getirilen bu sınırlama, yerinde olmamıştır (EREM, Faruk: *Anayasa ve Savunma Hakkı*, ABD., Yıl 1963, Sayı 1, s. 183). İddia ve savunma hakkıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet/ŞAHİN, Cumhur: *İddia ve Savunma Hakkı*, in: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2001, cilt V, sayı 1-2, sh. 84 vd.

rumda "tanıklıktan çekinme hakkı"nın varlığını kabul etmektedir. Bu anlayış, bilginin ilişkin olduğu kişiyi değil, bilgiye vakıf olan kişiyi esas almaktadır. Halbuki doğru değerlendirme, bilginin ilişkin olduğu kişiden hareketle yapılmalıdır. Bu nedenle "tanıklıktan çekinme hakkı"ndan değil, **aleyhe tanıklık yapmama yükümlülüğü**nden söz etmek gerekir. Nitekim CMK'da "tanıklıktan çekinme hakkı" ibaresi kullanılmamıştır. CMK'ya göre, avukatlar, stajyerleri ve yardımcıları, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgilerle ilgili olarak aleyhe tanıklıktan çekinme yükümlülüğü altındadırlar (m. 46, f. 1, bent a). Hatta, bu kişiler, belirtilen bilgileri, ilgilinin rızası olsa bile, tanık olarak açıklayamazlar (CMK, m. 46, f. 2)⁴⁷⁸.

Bu durum karşısında:

- a) Avukat, müdafiliğini üstlendiği ve hatta, müdafiliğinden yararlanmak için kendisine başvuran kişinin suç işlediğini öğrenmesi halinde, bu suçu bildirmekle yükümlü değildir. Bu hususun, TCK'nın 279. maddesinde tanımlanan "*Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi*" suçu ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- b) Avukat, müdafiliğini üstlendiği ve hatta, müdafiliğinden yararlanmak için kendisine başvuran kişinin saklandığı yeri öğrenmesi halinde, bulunduğu yeri bildirmekle yükümlü değildir. Bu hususun, TCK'nın "*Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme*" başlıklı 284. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçla ilgili olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir⁴⁷⁹.
- c) Avukat, müdafiliğini üstlendiği ve hatta, müdafiliğinden yararlanmak için kendisine başvuran kişinin işlediği suça ilişkin delillerin saklandığı yeri öğrenmesi halinde; bunların bulunduğu yeri, suçu takibe yetkili makam veya mercilere bildirmekle yükümlü değildir. Bu husus, TCK'nın 284. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan suçla ilgili olarak göz önünde bulundurulmak gerekir⁴⁸⁰.

II. Ancak, işaret etmek gerekir ki, sır saklama yükümlülüğü ve dolayısıyla, tanıklıktan çekinme hakkı, avukata, bazı davranışlarda bulunma yetkisini vermektedir. Şöyle ki:

⁴⁷⁸ Avukatlar bakımından **sır saklama yükümlülüğü**nün dayanağını 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun "*Sır saklama*" başlıklı 36. maddesi oluşturmaktadır. Söz konusu maddenin birinci fıkrasında "*Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya ... avukatlık görevi ... dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.*" hükmüne yer verilmiştir. Ancak, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında sır saklama yükümlülüğüyle bağlantılı olarak **tanıklıktan çekinme hakkı** düzenlenirken, "*iş sahibinin muvafakatini almış olmaları*" halinde avukatın tanıklık yapabileceği belirtilmiştir. İşaret etmemiz gerekir ki, hukuka aykırı olan bu hüküm, Ceza Muhakemesi Kanununun 46. maddesinin ikinci fıkrası hükmüyle **ilga edilmiştir**.

⁴⁷⁹ YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa: *Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu*, Cilt VI, Ankara 2010, sh. 8085 vd.

⁴⁸⁰ YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, TCK, VI, sh. 8087 vd.

a) Avukat, müdafiliğini üstlendiği kişinin işlediği suça ilişkin delilleri yok edemez, silemez, **gizleyemez**, değiştiremez ve bozamaz.

Bu bağlamda avukat; şüpheli veya sanığın, savunmasında gerçeğe aykırı açıklamada bulunmasına yönelik telkinlerde bulunamaz. Öncelikle belirtmek gerekir ki, şüpheli veya sanığın, her ne kadar "susma hakkı"nın varlığından söz edilmekte ise de, **"yalan söyleme hakkı" bulunmamaktadır**⁴⁸¹. Ancak, açıklamada bulunma halinde gerçeğe uygun, doğru beyanda bulunulmasına ilişkin bu yükümlülüğün, bir "hukuki yükümlülük" olarak değil; bir "ahlâkî yükümlülük" olarak anlaşılması gerekir. Çünkü, şüpheli veya sanığın bu yükümlülüğe aykırı davranışta bulunması halinde, *Kanunlarda* bir müeyyide öngörülmemiştir⁴⁸². Ancak, şüpheli veya sanık bakımından bir şahsi cezasızlık sebebi olarak değerlendirilmesi gereken bu durumun avukat açısından söz konusu olmadığını belirtmek gerekir.

Aksi yöndeki davranışlar, avukat bakımından TCK'nın *"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"* başlıklı 281. maddesinde tanımlanan suçu oluşturur. Müdafilik göreviyle bağlantılı olarak avukat, aynı zamanda kamu görevlisi sıfatını taşıdığı için, 281. maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulama kabiliyeti bulur. Buna göre, söz konusu *"suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır."*

b) Avukat, yakalanmasını, tutuklanmasını, hakkında hükmolunan cezanın infazından kurtulmasını sağlamak için, müdafiliğini üstlendiği kişiyi, örneğin evinde veya bürosunda saklayamaz, örneğin yurt dışına kaçırılmasını sağlamak için, imkan sağlayamaz. Aksi yöndeki davranışlar, TCK'nın *"Suçluyu kayırma"* başlıklı 283. maddesinde tanımlanan suçu oluşturur⁴⁸³. Dikkat edilmelidir ki, söz konusu *"suçun oluşabilmesi için, kayırılan kişinin araştırma, yakalanma, tutuk-*

⁴⁸¹ ŞAHİN, Cumhur: *Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması*, Ankara, 1994, sh. 114-116; PETERS, Karl: *Strafprozess, Ein Lehrbuch*, Heidelberg, 1985, § 28, IV, 2; EREM, Faruk: *Diyaletik Açısından Ceza Yargılaması Hukuku*, 6. bası, Ankara, 1986, sh. 160; CİHAN, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, yıl 1984, cilt CL, sayı 1-4, sh. 145; WESSELS, Johannes, JuS 1966, sh. 173; pek açık olmamakla birlikte, KUNTER, Nurullah: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 9. bası, İstanbul, 1989, no. 252. Ayrıntılı bilgi için ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Zanlısı Kişinin Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü ve Bunun Hukuki Sonuçları*, in: Hukuk Araştırmaları (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), yıl 1995, cilt 19, sayı 1-3, sh. 129 vd.

⁴⁸² ŞAHİN, sh. 114-116; PETERS, § 28, IV; EREM, sh. 159; TOSUN, Öztekin: *Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri*, cilt I, Genel Kısım, 4. bası, İstanbul, 1984, sh. 641, 753; ROXIN, Claus: *Strafverfahrensrecht*, 20. Auflage, München, 1987, § 25, III, 3. *Yenisey*, "sanığın **yalan** söylemesi(nin) de bir **hak** olarak tanınabil"eceği fikrindedir (YENİSEY, Feridun: *Duruşma ve Kanunoyolları*, İstanbul, 1988, sh. 97). "Türk" doktrinde ileri sürülen ve dünyada başka bir bilim adamı tarafından ileri sürüldüğünü henüz tespit edemediğimiz bir fikre göre, şüpheli veya sanığın ve hatta hükümlünün **"kaçma hakkı"** mevcuttur (?) (ÖZEK, Çetin: *Türk Ceza Kanununun 50 Yılında Devlete Karşı Suçlar*, in: Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Karşısında TCK'nın 50 Yılı Ve Geleceği, İstanbul, 1977, sh. 583).

⁴⁸³ YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, TCK, VI, sh. 8076.

lanma veya hükmün infazından kurtulması amacıyla hareket edilmesi gerekir. Böyle bir amaç güdülmemekle beraber, kişinin insani mülahazalarla bazı ihtiyaçlarının karşılanmış olması durumunda, söz konusu suç oluşmayacaktır.”⁴⁸⁴.

c) Avukat, tanık olarak dinlenecek olan kişinin gerçeğe aykırı olarak açıklamada bulunmasını sağlamaya yönelik teşebbüste bulunamaz. Aksi yöndeki davranışlar, TCK’nın 272. maddesinde tanımlanan **yalan tanıklık suçuna azmettirmen** dolaylı cezalandırılmayı gerektirmektedir. Hatta, tanık olarak dinlenecek kişiler doğrudan muhatap alınmaksızın, “*bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma (devam ederken) savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda*” bulunulmasının da ayrı bir suç oluşturduğunu göz önünde bulundurmak gerekir (TCK, m. 288).

d) Avukat, ister hukuk davası olsun ister bir suçla ilişkin olarak yürütülen soruşturma veya kovuşturma olsun, hakimi, C. savcısını, bilirkişiyi veya tercümanı **hukuka aykırı olarak** etkilemeye teşebbüs edemez. Dikkat edilmelidir ki, burada hukuka aykırı olarak etkilemekten söz edilmektedir. Elbette ki avukat vekil veya müdafî sıfatıyla iddia ve savunma hakkını kullanmak suretiyle, bir hususla ilgili olarak hakimi, C. savcısını, bilirkişiyi veya tercümanı etkilemeye çalışacaktır. Bir görevin yerine getirilmesinin ve buna bağlı olarak bir hakkın kullanılmasının söz konusu olduğu hallerde ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidilemeyeceği izahıtan varestedir. Buna karşılık, hakimi, C. savcısını, bilirkişiyi veya tercümanı iddia ve savunma hakkının kullanılmasının dışında başka yöntemlerle etkileme girişimleri, TCK’da suç olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda TCK’nın “*Yargı görevi yaparı etkileme*” başlıklı 277. maddesi ile “*Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs*” başlıklı 288. maddesinde yer alan suç tanımlarını göz önünde bulundurmak gerekecektir.

e) Soruşturma işlemleri gizlidir. Ancak, bu gizlilik, soruşturmaya süje olarak katılma hak ve yetkisine sahip olan kişiler bakımından kural olarak söz konusu değildir. Başka bir deyişle, müdafî sıfatıyla avukat, yürütülen soruşturma işlemlerinin içeriğine ilişkin bilgilere kural olarak ulaşmak hak ve yetkisine sahiptir. Bu bağlamda CMK’nın 149 ve devamı maddelerini ve özellikle 153. maddesi hükümlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu hükümlere göre, müdafî sıfatını taşıyan ya da müdafilik sıfatını henüz taşımamakla birlikte, bu görevi üstlenmesi talebiyle kendisine başvuru alan avukat, soruşturma dosyasını inceleme yetkisini haizdir. Ancak avukat bu suretle öğrendiği soruşturma işlemlerinin içeriğini, yetkisiz kişilere açıklamamakla yükümlüdür⁴⁸⁵. Ancak,

⁴⁸⁴ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 674.

⁴⁸⁵ Bunun için, yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin dosyayı hangi avukatın incelediğinin, dosya içeriğinden anlaşılması gerekmektedir.

avukat, soruşturma konusu fiilin arzettiği özellik dolayısıyla bir başkasının uzmanlık bilgisinden yararlanma ihtiyacı duyabilir. Bu durumda avukat, soruşturma işlemleri kendisi bakımından gizli olan kişiye, uzmanlık bilgisinden yararlanmak amacıyla, soruşturma dosyasını inceletme gereğini hissedebilir. Bu durumda bir hukuka aykırılığın söz konusu olmadığı, izahtan varestedir. Ancak, avukat, soruşturma dosyasının içeriğiyle ilgili olarak örneğin basın ve yayın organlarına açıklama yapamaz. Bu mülahazayladır ki, TCK'nın 285. maddesinde **gizliliğin alenen ihlali** suç olarak tanımlanmıştır. Başka bir ifadeyle, yetkisiz kişilerin eline geçen soruşturma dosyasına ilişkin bilgilerin, örneğin sanık veya tanık ifadelerinin, alenilik kazanması halinde, gizlilik ihlali dolayısıyla ceza sorumluluğu cihetine gidilecektir. Nitekim, söz konusu maddenin gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir: “*Avukat adalete hizmet eden bir mesleğin mensubu olarak dosyadan elde ettiği bilgileri kanunun verdiği olanaklar çerçevesinde sadece müvekkilini savunması için kullanacak, bunları yayınlamak, örneğin medyaya vermek gibi fiillere girişemeyecektir. ... Bu maddede, soruşturma evresinde yapılıp alenî olmayan gizli işlemlerin, yani ceza usulüne ilişkin kanunların netice ve içeriklerinin gizli olduğunu belirttiği işlem içeriklerinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin sağlanması, suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu nedenle cezaya hükmedilebilmesi için, bilgilendirmenin alenen gerçekleştirilmesi gerekir.*”^{486,487}

Ekskurs 3. Kolluğun Suçlulukla Mücadele ve Suç Olaylarının Açıklığa Kavuşturulması Bağlamında Suç Oluşturan Fiilleri İşleyip İşleyemeyeceği Sorunu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **09.11.2010** tarihli ve E. 2010/8-156, K. 2010/225 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; kolluk görevlileri, bu sıfatlarını gizleyerek, sahte olarak üretilmiş olan banknotları piyasaya sürmeye çalışan kişilerle irtibata geçerler; sahte olarak üretilen bu banknotlardan belirli bir miktarda %50 komisyon karşılığında teslim alma konusunda bu kişilerle mutabakat sağlarlar. Bilahare banknotların teslim alınacağı sırada, kişiler yakalanır ve sahte olarak üretilen banknotlara elkonulur.

Benzer olaylarla günlük hayatta sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Örnek 1. Kolluk görevlisi, uyuşturucu madde satmaya çalışan kişilerle irtibata geçerek, kullanmak için ihtiyaç duyduğundan bahisle bu kişilerden uyuşturucu madde satın almak ister. Uyuşturucu maddenin teslim alınması sırasında, kişiler yakalanır ve uyuşturucu maddeye elkonulur.

⁴⁸⁶ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 676 vd.

⁴⁸⁷ Bu bağlamda özellikle işaret etmek gerekir ki, soruşturma işlemlerinin içeriğinin örneğin basın ve yayın organlarında açıklanmak suretiyle gizliliğin ihlal edilmesi halinde, TCK'nın 285. maddesinde tanımlanan suç, sadece bu bilgileri basın ve yayın organlarına veren kişi tarafından değil, bu bilgileri basın ve yayın organlarında yayımlayan kişi tarafından da işlenmiş olmaktadır.

Örnek 2. A, meşru bir işinin görülmesi için kamu görevlisi B'ye başvurur. B, başvuru konusu işi yapması için, A'dan kendisine belli bir miktar para vermesi yönünde talepte bulunur. Talebi kabul etmiş izlenimi uyandıran A'nın ihbarda bulunması üzerine, kolluğun kontrol ve denetimi altında B'ye talep ettiği para verilirken suçüstü yakalanması sağlanır.

Dikkat edilmelidir ki, bu tür olaylarda, suç işlemeyi düşünmeyen, tamamen masum olan kişilerin suça itilmesi, suç işlemeye teşvik edilmesi söz konusu değildir. **Bu olaylarda kişiler suç yoluna girmişlerdir.** Bu nedenle, kolluk görevlilerinin suçların açıklığa kavuşturulması ve suç yoluna girmiş olan kişilerin ortaya çıkarılmasını temin amacına yönelik olarak, suç konusu eşyayı kabul eden veya satın alan rolünü üstlenmesinde ya da kamu görevlisine menfaat sağlama görüntüsü verilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Ancak, **kolluk görevlileri, belli bir suç olayını ortaya çıkarabilmek amacıyla da olsa, suç işlemeyi düşünmeyen, tamamen masum olan kişileri suç işlemeye teşvik edemez ve suça itemezler.** Aksi takdirde kolluk görevlilerinin işlenen suç nedeniyle dolaylı fail veya azmettiren sıfatıyla sorumlu tutulmaları gerekir⁴⁸⁸.

Kolluk görevlileri, bir suç olayını bütün yönleriyle ortaya çıkarabilmek için, bir suçun icrası sürecinde de görev üstlenebilirler. Örneğin Van'da kolluk görevlileri tarafından önemli miktarda uyuşturucu maddenin yurt dışından ülkeye sokulduğu tespit edilir. Ancak, kolluk görevlileri bu olaya, uyuşturucu maddeye elkoymak ve failleri yakalamak suretiyle, hemen müdahil olmazlar. Organize bir şekilde icra edilen bu uyuşturucu madde ticaretinin diğer yönlerinin (arka planda bulunan organizatörlerin, bu ticaretin icrası bağlamındaki para transferlerinin) açıklığa kavuşturulmasını sağlamak amacına yönelik olarak, kolluk görevlileri, bu uyuşturucu maddenin naklinde ve teslimatında görev üstlenebilirler (**kontrollü teslimat**). Bu şekilde bir görev üstlenmenin hukuka uygun kabul edilebilmesi için;

- a) başkaları tarafından icrasına başlanmış bir uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun olması,
- b) kolluk görevlilerinin, bu suçun icrası devam ederken olaya müdahil olması,
- c) kolluk görevlilerinin, suçun icrası tamamlanmadan önce suç ortaklarının yakalanması amacıyla hareket etmesi,

⁴⁸⁸ “Bir polis memuru tarafından tahrik edilen ve genellikle suçluyu polisin ağına düşürmek için sahneye konulan olaylarda, eğer failin yaptığı hareket elverişli veya mevzu mevcut ise cezalandırılacağından şüphe edilmemelidir. Eğer tahrikçi ajanın faaliyetine rağmen, fiilin bütün unsurları ile gerçekleşmesi mümkün ise, tamamlanmış veya teşebbüs halinde kalmış suçlar söz konusu olacaktır. Hareketin elverişsiz sayılabilmesi için, elverişsizliğin harekete ilişkin olması gerekir. Hareketin dışında kalan, ona yabancı bir sebeple yaratılan elverişsizlik, bu anlamda bir elverişsizlik değildir. Polis tarafından suçluları ele geçirmek için alınan tedbir ve hazırlanan tertipler, neticenin meydana gelmesini daima imkansız kılmazlar. Birçok halde zayıf da olsa bir başarı ihtimali olabileceği unutulmamalıdır.”: CGK, 30.4.1984, 5-43/154 (YKD, Temmuz 1984, sh. 1096).

d) nakli gerçekleştirilen uyuşturucu maddenin kime ve ne suretle teslim edileceğine ilişkin şartların kolluk tarafından değil, temas kurulan suç ortakları tarafından belirlenmesi,

e) uyuşturucu maddenin teslimi sırasında veya hemen akabinde, temas kurulan suç ortaklarının yakalanmasının ve teslimatı gerçekleştirilen **uyuşturucu maddede elkonulmasının sağlanması**,

gerekir. Aksi takdirde, yani bütün bu şartların birlikte gerçekleşmemesi halinde, uyuşturucu maddenin naklinde görev alan kolluk görevlilerinin de suça iştirake ilişkin hükümlere göre cezalandırılması gerekir.

Bu itibarla, örneğin bir rüşvet ilişkisinin ortaya çıkarılması bağlamında yapılan teknik takip sırasında rüşvet verilmeden önce olaya müdahil olunması gerekir. Başka bir ifadeyle, teknik takibi yapan kolluk görevlilerinin, rüşvet olarak verilmek istenen paraya suç tamamlanmadan önce elkonulmasını sağlaması gerekir.⁴⁸⁹ Aksi takdirde, bu kişilerin ihmali davranışları nedeniyle rüşvet suçuna yardım eden sıfatıyla sorumlulukları yoluna gidilmesi gerekir.

Hukuk sistemimizde, bir hukuka uygunluk sebebi olarak kontrollü teslimata ilişkin hükümlere, 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 2, 10, 11 ve 13. maddeleri ile 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 21. maddesinde yer verilmiştir.⁴⁹⁰

⁴⁸⁹ Bu bağlamda Ceza Muhakemesi Kanununa aşağıdaki içerikte bir hüküm konulmasını sağlama yönündeki girişimimiz, sonuçsuz kalmıştır:

“Kolluk;

a) İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

b) Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

c) Teknik araçlarla izleme,

ç) Kontrollü teslimat,

yöntemleriyle delil elde edilmesi sürecinde, suçun icrası tamamlanmadan, kesintisiz suçlarda ise suçun icrası bitmeden, suçüstü hükümleri çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasını ve suç konusu olan, suçtan elde edilen veya suçun işlenmesinde kullanılan eşyaya elkonulmasını sağlamakla yükümlüdür.”

⁴⁹⁰ 4208 s. Kanunda kontrollü teslimat şu şekilde tanımlanmıştır:

“Kontrollü Teslimat: **Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer hertürlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini, ... ifade eder.**” (m. 2, bent c).

Kontrollü teslimatın şartları, 4208 s. Kanunun 10. maddesinde belirlenmiştir:

“Kontrollü Teslimatın Şartları

Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün yapısını teşhis edebilmek, örgütün yöneticileri ve üyeleri hakkında, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak bilgi toplamak amacıyla, kolluk görevlilerinin örgüt mensubu görünümlü bu örgütün içine sokulmasında hukuken bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, bu amaçla görevlendirilen kişiler, bu görevleri çerçevesinde faaliyet icra ederken suç işleyemezler, kişileri suç işlemeye teşvik edemezler; sadece örgütün yapısıyla ve işlenen suçlarla ilgili olarak bilgi toplar.

Madde 10– *Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;*

a) *Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,*

b) *Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkan bulunmaması,*

c) *Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,*

d) *Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,*

e) *Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;*

1. *Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağına talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,*

2. *Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması,*

Zorunludur.”

Kontrollü teslimat kararı verme yetkisine ve uygulama usulüne ilişkin hükümler, 4208 s. Kanunun 11 ve 13. maddelerinde belirlenmiştir:

“Kontrollü Teslimat Kararı ve Usulleri

Madde 11 – *Kontrollü teslimata, 10’uncu maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı (Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulu tarafından 3713 s. Terörle Mücadele Kanununun 10. maddesi hükümlerine göre görevlendirilen Cumhuriyet savcıları –yazar–) tarafından karar verilir.*

İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir.

Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.”

“Yetkili Mahkeme

Madde 13–*Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.”*

Kontrollü teslimata ilişkin işlemleri yapmaya yetkili kamu otoriteleri de 5607 s. Kanunun 21. maddesinde belirlenmiştir. Dikkat edilmelidir ki, genel kolluk gibi kamu otoriteleri tarafından söz konusu *“kontrollü teslimat işlemleri, ancak bir soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısının izniyle ve kararıyla yapılabilir”* (TBMM Adalet Komisyonunun 5.12.2006 tarihli ve Esas: (1/1240), (2/403), (2/644), Karar: 114 sayılı Raporu [TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1275, sh. 17; ÖZGENÇ, İzzet: *Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu*, Ankara, 2007, sh. 72]).

yabilirler. Nitekim Ceza Muhakemesi Kanununun “Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi” başlıklı 139. maddesinde;

“Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür.” (f. 4)

“Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez ve görevlendirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz.” (f. 5)

hükümlerine yer verilmiştir.

Gizli soruşturmacının, 139. maddenin beşinci fıkrası hükmündeki kayıtla, örgüt mensubu görüntüsüyle örgütün içinde yer alması, bir suç oluşturmamaktadır. Çünkü gizli soruşturmacının amacı, suç işlemek değildir. Örgüt yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarının oluşabilmesi için, kişinin yönettiği veya katıldığı örgütün suç işlemek için kurulmuş bir örgüt olduğunu bilmesi ve bu amacı benimseyerek örgütün yönetimine katkı vermesi veya örgüte intisap etmesi gerekir. Oysa gizli soruşturmacı, örgütün amacını bilmekle birlikte, suç işlemek amacıyla örgüte katılmamaktadır. Aksine, örgütün faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi toplamak üzere örgütün yapısında yer almaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kolluk görevlilerinin kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirebilmek için, bazı durumlarda kolluk görevlisi sıfatları gizlenebilir. Bu itibarla, kolluk görevlisi, örneğin **seyyar satıcı** görüntüsüyle, suç ve suçlulukla ilgili bilgi toplayabilir. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda **gizlenen** sadece kişinin **kolluk görevlisi sıfatıdır**. Başka bir ifadeyle, bu durumda gizlenen kişinin kolluk görevlisi olduğu hususudur, kimliği değil. Bu bağlamda kolluk görevlisine, gerçek kimliği gizlenerek anonim bir isimle nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgesi düzenlenemez. Aksi takdirde belgede sahtecilik suçunun oluşacağı izahtan varestedir.

Buna karşılık, CMK’nın 139. maddesi hükümlerine göre görevlendirilen gizli soruşturmacının gerçek kimliğini gizlemeye yönelik olarak, anonim bir isimle nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgesi düzenlenerek bu kişiye verilebilir. Ancak bu konuda bir karar verilmesi gerekir. Bu karar, gizli soruşturmacı görevlendirilmesine karar veren hakim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilebilir⁴⁹¹. Bu itibarla, hakim veya Cumhuriyet savcısının kararı olmadan gerçeğe

⁴⁹¹ Gizli soruşturması görevlendirilmesine ve gerçek kimliğini gizlemeye yönelik olarak bu kişiye verilmek üzere anonim bir isimle nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgesi düzenlenmesine ilişkin kararlar, bu kararlar çerçevesinde kimlik belgesi düzenlenmesine ilişkin işlemler ve düzenlenen belge içeriklerine ilişkin bilgiler **gizli** olup, soruşturmanın yürütüldüğü Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde muhafaza edilirler (CMK, m. 139, f. 3).

CMK’nın söz konusu düzenlemesine göre, anonim bir isimle düzenlenen nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgesi, gizli soruşturmacı tarafından hukuki işlem tesisinde de kullanıla-

aykırı olarak hiç kimse ile ilgili olarak anonim bir isimle nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgesi düzenlenemez.

CMK'nın gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin 139. maddesi hükümleri dışında; mevzuatımızda, ister adli kolluk ister önleyici kolluk ister istihbarat faaliyeti çerçevesinde olsun, kolluk veya sair kamu görevlisine, gerçek kimliğini gizlemeye yönelik olarak, kendi fotoğrafını taşıyan ve fakat anonim bir isimle nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgesi düzenlenmesine imkan tanıyan bir hüküm bulunmamaktadır⁴⁹².

Ekskurs 4. Kolluğun Sürücülerle İlgili Olarak Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Denetimi Yapma Yetkisi ve Sınırları

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı **Karayolları Trafik Kanununun** 24.5.2013 tarihli ve **6487** sayılı Kanunla (m. 19) değiştirilen 48. maddesinde, sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının ya da alkollü olup olmadıklarının denetimi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol etkisindeyken araç kullanma dolayısıyla uygulanabilecek yaptırımlar ve bu haldeyken trafik kazasına sebebiyet vermenin hukuki sonuçları ile ilgili olarak önemli düzenlemelere yer verilmiştir.

I. Alkol veya uyuşturucu madde etkisindeyken sürücü olarak trafiğe çıkmanın kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından bir tehlike oluşturduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun **“Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı”** başlıklı 48. maddesinde, **“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasak”**lanmıştır (f. 1).

Hatta bu durum kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından **somut** bir tehlike oluşturduğu takdirde fiil, TCK'da **suç** olarak tanımlanmıştır:

“Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ... emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi (iki yıla kadar hapis cezası ile) cezalandırılır.” (m. 179, f. 3)

II. Sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı ya da alkollü olup olmadıkları, kollukça idari kolluk faaliyeti çerçevesinde denetlenebilir. Bu denetleme, **“teknik cihazlar”** kullanılarak yapılır (2918 s. K, m. 48, f. 2).

Trafik kazasına karışmış sürücülerin bu denetime tabi tutulmaları zorunludur. Dikkat edilmelidir ki, bu denetim bağlamında, belirli bir veya birkaç trafik kura-

bilecektir: **“Bu kimlikle hukukî işlemler yapılabilir.”**. Herhangi bir kayıt ve sınırlama içermeyen bu hükmün **sakıncalı** olduğunu düşünmekteyiz.

⁴⁹² Kamu görevlisi sıfatı taşımamakla birlikte, 5726 s. Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre, hakkında “Tanık Koruma Tedbiri” alınan kişilerin de çok sıkı şartlara bağlı olarak kimliklerine ilişkin bilgi ve belgelerin değiştirilmesi uygulaması yapılabilir (m. 5).

lını ihlal ederek trafik kazasına sebebiyet vermiş sürücülerden değil, “**trafik kazasına karışmış sürücü**”den söz edilmektedir.

Kişi trafik kazasına karışmış olmakla beraber, kendisi herhangi bir trafik kuralını ihlal etmemiş olabilir. Bir başkasının kural dışı bir davranışı da trafik kazasının oluşumuna sebebiyet vermiş olabilir. Bu durumda, trafik kazasına karışan sürücüye izafe edilebilecek herhangi bir yükümlülük ihlali ve kusur söz konusu olmayabilir.

Bu nedenle, trafik kazasına karışmış olan sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının ya da alkollü olup olmadığının tespiti amacıyla denetime tabi tutulması, bir **zorunluluk** arz etmektedir⁴⁹³.

⁴⁹³ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**’nun **22.1.2013** tarihli ve E. 2012/9-1235, K. 2013/22 sayılı Kararına konu teşkil eden olay şu şekilde gelişir: SM, **15.7.2005 günü, saat 23.00** sıralarında havanın açık, gece vakti, sevk ve idaresindeki otomobil ile asfalt kaplama, yol şerit çizgileri çizilmiş, iki yönlü, bölünmemiş, zemini kuru, eğimsiz, aydınlatması olan karayolunda seyir halinde iken, trafik lambası bulunmayan bir noktada sola karşıya geçmek üzere sinyal verip yol üzerinde beklemeye başlar. Yolu solundaki akaryakıt istasyonuna girmek için karşı şeride geçtiği sırada karşı istikametten gelen MT’nin sevk ve idaresindeki otomobille çarpışır. Çarpma sonucu SM’nin kullandığı araç 9 metre sürüklenir; MT’nin kullandığı araç da çarpma noktasına göre 5 metrelik mesafede bulunur.

Kazada, SM’nin kullandığı aracının sağ ön koltuğunda oturan KT ölür. YT yaşamını tehlikeye sokacak, MM basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif, sürücü SM yaşamını tehlikeye sokacak ve organlarında işlev kaybı oluşacak ve diğer sürücü MT ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif şekilde yaralanır.

Dosyada bulunan bilirkişi raporlarına göre, kaza, SM’nin, sola karşıya geçmek “*istediği sırada şerit ihlali yapması sonucu*” meydana gelmiştir. MT de, “*araç hızını görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak*” yönündeki yükümlülüğe aykırı hareket etmiştir.

Karasu Devlet Hastanesince 16.7.2005 günü saat 00.00’da düzenlenen rapora göre, sürücü SM’nin “*klinik olarak alkollü olduğu*”, diğer sürücü MT’nin “*acil serviste alkolmetre ile yapılan ölçüm sonucu*”nda 1.23 promil alkollü olduğu tespit edilir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine **16.7.2005 günü saat 00.30’da SM’den kan örneği alınır ve bunun Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesince incelenmesi sonucu düzenlenen 18.5.2005 tarihli rapora göre**, SM’nin 0.20 promil alkollü olduğu tespit edilir.

Ceza Genel Kurulu’na göre, SM’nin, “*kendi şeridindeki trafik yoğunluğundan dolayı (araçta bulunan MM’nin) de uyarısı üzerine aynı şeritte ve arkasından gelen kamyonun güvenli şekilde geçişini beklediği, dikkatini arkasından gelen aracın geçişine yoğunlaştıran SM’nin bu geçiş tamamlandıktan sonra karşı şeritten araç gelip gelmediğini kontrol etmeden aracını hareket ettirerek karşı şeride girerek kazanın meydana gelmesine kusuruyla neden olduğu, ancak dosya kapsamına göre sanığın meydana gelen neticeyi öngörmediği anlaşıldığından sürücü SM bakımından bilinçli taksirin şartları oluşmamıştır.*”

Diğer sürücü MT ise; “*yönetimindeki araçla kendi şeridinde aksi ispatlanamayan savunmasına göre 80 km hızla seyir halinde iken, SM’nin kullandığı aracın karşı şeritten kendi şeridine girmesi üzerine kendi şeridinde bu araca çarptığı, sanığın karşı şeritten akan yoğun trafik içinden her zaman bir aracın yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giriş yapabileceği hususunu gözardı ederek yola dikkatini vermediği, aracının hızını yol ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı, bu suretle kazanın meydana gelmesine kusuruyla neden olduğu, ancak dosya kapsamına göre sanığın meydana gelen neticeyi öngörmediği anlaşıldığından, bu sanık bakımından da bilinçli taksirin şartlarının oluşmadığının kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.*”

Ceza Genel Kurulu’nun bu kararında sürücülerin alkollü olup olmadıklarının tespiti bağlamında izlenen yöntemin doğru olup olmadığı ve alkollü oldukları hususları değerlendirme konusu yapılmamıştır.

Ancak belirtmek gerekir ki, bu trafik kazasının “**yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazası**” olması gerekir (2918 s. K, m. 48, f. 3, birinci cümle).

Trafik kazasına karışmış olmakla beraber, “teknik cihaz” kullanılarak yapılan denetime müsaade etmeyen bu sürücü, kolluk tarafından “*en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücu(dun)dan kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.*” (2918 s. K, m. 48, f. 3, ikinci cümle). Kolluk görevlileri, bu işlem bağlamında **zor kullanma yetkisine** sahiptirler. Ancak belirtmek gerekir ki, bu işlemin yapılabilmesi için, **hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararına** ihtiyaç vardır. Başka bir ifadeyle, trafik kazasına muttali olan kolluk görevlisi, kazaya karışan sürücünün teknik cihazla yapılan denetime müsaade etmemesi halinde, Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek, söz konusu kararın alınmasını sağlayacaktır (CMK, m. 75, f. 1). Kanaatimizce, trafik kazasına karışmış olan sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının ya da alkollü olup olmadığının tespiti amacıyla vücutundan örnek alınması gerektiği için, bu bağlamda gecikmeye tahammülün olmadığı ve **gecikmesinde sakınca bulunan** bir **halin** varlığını kabul etmek gerekir.

Trafik kazasına karışmış sürücünün vücutundan kan, tükürük veya idrar gibi örnekler “**ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından**” alınabilir (CMK, m. 75, f. 3). Dikkat edilmelidir ki, bu işleme tabi tutulan sürücü ile sağlık görevlisi arasında “hasta - hekim ilişkisi” mevcut değildir. Bu işlem, **bilirkişilik görevi** bağlamında icra edilen bir görevdir. Bu nedenle, vücutundan kan, tükürük veya idrar gibi örnek alınabilmesi için, söz konusu işleme tabi tutulan **sürücünün rızasının aranmasına gerek yoktur**.

Önemle işaret etmek gerekir ki, trafik kazasına karışmış olan sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının ya da alkollü olup olmadığının tespiti amacıyla vücutundan örnek alınabilmesi için, sürücü hakkında üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle başlatılmış bir soruşturmanın varlığı, şart olarak aranmayacaktır (2918 s. K, m. 48, f. 3, üçüncü cümle). Ancak bu işlemler, gerçekleşen trafik kazası dolayısıyla bir **adli soruşturma** başlatılmasını gerekli kılmaktadır. Bu soruşturma, gerçekleşen trafik kazasının sonuçlarına göre, örneğin taksirle ölümüne veya yaralamaya sebebiyet verme ya da trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları dolayısıyla başlatılmış bir soruşturma olabilir.

Dikkat edilmelidir ki, vücuttan kan, olayın hemen akabinde alınmalıdır. Olayla vücuttan kan alınması arasındaki zaman uzadıkça, kandaki alkol miktarında olay anına nazaran **azalma** meydana gelecektir. Keza vücuttan alınan kan en geç 3-4 saat içinde alkol muayenesine tabi tutulmalıdır. Vücuttan alınan kan içindeki alkol miktarında zaman geçtikçe **artış** meydana gelir. Ancak vücuttan alınan kan **sodyum flörür** karışımıyla +4°C ısıda uzun süre saklanabilir.

Yapılan denetimde, trafik kazasına karışmış olan sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığının ve alkollü olmadığının anlaşılması halinde, şayet kendisine izafe edilebilecek ve bu kazanın oluşumu bakımından etkili olan başka bir trafik kuralı ihlali söz konusu değilse, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi gerekir.

Gerçekleşen trafik kazası sonucunda sürücünün ölmüş veya ağır bir şekilde yaralanmış olması sebebiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını ya da alkollü olup olmadığını olay mahallinde “teknik cihazla” tespit etme imkanı bulunmayabilir. Bu durumda, Cumhuriyet savcısının kararı üzerine, ölen veya yaralanan sürücünün sevk edildiği adli tıp kurumunda, adli tabiplikte veya sağlık kuruluşunda vücudundan örnek alınarak inceleme yapılabilir (2918 s. K, m. 48, f. 4).

III. Sürücü alkollü olmakla birlikte, alkollü olarak araç kullanmanın dışında başka herhangi bir trafik kuralını ihlal etmemiş olabilir. Belirtmek gerekir ki, alkollü olmak, her zaman kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından somut bir tehlike oluşturmaz. Bu nedenle, davranışlarını yönlendirme yeteneğini etkilemeyecek ölçüde alkollü olan sürücü ile ilgili olarak, alkol etkisindeyken araç kullanmak dışında başka herhangi bir trafik kuralını ihlal etmese bile, sadece idari yaptırım uygulanabilecektir.

Ancak, bunun için önce kişinin alkollü olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bir trafik kazasına karışmamış ve hatta somut herhangi bir trafik kuralını ihlal etmemiş olan sürücüler de, **idari kolluk görevi** bağlamında alkollü olup olmadıklarının tespiti için bir denetime tabi tutulabilirler. Ancak bu denetimin yapılabilmesi için, makul bir sebebin bulunması gerekir. Denetimin örneğin alkollü içki tüketimi yapılan bir bölgede, gecenin geç saatlerinde yapılması gibi hallerde, bu makul sebebin varlığını kabul etmek gerekir.

Trafik kazasına karışmamış sürücünün, alkollü olup olmadığının tespiti amacıyla denetime tabi tutulmayı salt kabul etmemesi, **idari yaptırım** uygulanmasını gerektirmektedir⁴⁹⁴.

“Hususi otomobil” statüsündeki araçların 0.50 ve daha düşük promil alkollü olan sürücüler bakımından bu hale özgü olarak herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir.

Ticari araçlar ve toplu taşıma araçları gibi “husussi otomobil” dışındaki araçların sürücüler bakımından ise 0.20 ve daha düşük promil alkollü olmaya özgü herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir. Zira örneğin portakal veya limon yemek suyetiyle de doğal olarak alınmış bu değerinde alkolün tespiti mümkün olabilmektedir.

⁴⁹⁴ Bu sürücülere “**2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.**” (2918 s. K, m. 48, f. 9).

Buna karşılık, “hususî otomobil”lerde **0.51 - 1.00** arasında, diğer araçlarda ise **0.21 - 1.00** arasında promil alkollü olduğu tespit edilen sürücülere, **idari para cezası** verilecektir (2918 s. K, m. 48, f. 5)⁴⁹⁵.

Bu sürücülerin sebebiyet verdikleri trafik kazasında başka kişi veya kişiler ölmüş veya yaralanmış olabilir. Bu durumda, sürücü hakkında TCK’nın ilgili suç hükümlerine istinaden soruşturma ve kovuşturma yapılacağı kuşkusuzdur. Alkollü olan sürücü hakkında başkasının ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet verdiği için TCK’nın ilgili suç hükümlerine istinaden soruşturma başlatılması, bu sürücüye 2918 s. Kanunun 48. maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre idari para cezası verilmesine engel teşkil etmeyecektir. Zira söz konusu fıkra “**fiilleri bir suç oluştursa bile**” ibaresine yer verilmiştir. Bu durum, 48. maddenin yedinci fıkrası ile de teyit edilmiştir. Bu düzenleme ile, 5326 s. Kabahatler Kanununun “*İçtima*” başlıklı ve genel hüküm mahiyetindeki 15. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün⁴⁹⁶ çeliştiğini ve bu çelişki karşısında özel hüküm olan 2918 s. Kanunun 48. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanması gerektiğini belirtmek gerekir.

Buna karşılık, 2918 s. Kanunun 48. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ölçülerde alkollü olan kişiye, alkollü olarak araç kullanmak dışında başka herhangi bir trafik kuralını ihlal etmese bile, sadece idari yaptırım uygulanmaktadır.

IV. Araç sürücüsünün 1.00 üzerinde, yani 1.10 ve daha yüksek promil alkollü olduğu hallerde, bir trafik kazasına sebebiyet verilmemiş olsa bile, kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana geldiği normatif olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle, 1.00 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanan sürücü, bir trafik kazasına sebebiyet vermemiş olsa bile, bu suretle başkalarının hayatını, sağlığını ve malvarlığını tehlikeye sokmakta ve **suç** işlemiş olmaktadır. Artık bu durumda sürücünün, TCK’nın 179. maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre cezalandırılması gerekir⁴⁹⁷.

⁴⁹⁵ Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öngörülen idari para cezası miktarı **700 TL**’dir. Ayrıca bu sürücülerin “*sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. ... Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır.*” (2918 s. K, m. 48, f. 5). Önemle belirtmemiz gerekir ki, bu hükümlere “*göre geri alınan sürücü belgesinin iade edilebilmesi için; ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla (2918 s.) Kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ... şarttır.*” (2918 s. K, m. 48, f. 13).

⁴⁹⁶ Söz konusu fıkra hükmü şu şekildedir:

“*Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.*”

⁴⁹⁷ “Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulunca, belirlenen alkol seviyesine göre bulguların ortaya çıkma eşiğinde sayılan etkenlere bağlı olarak değişebilen derecelerde bireysel farklılıklar gö-

V. Araç sürücülere, **önleyici kolluk** faaliyeti çerçevesinde sadece alkollü olup olmadıklarının tespiti amacıyla değil, **uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında olup olmadıklarının tespiti amacıyla** da denetime tabi tutulabileceklerdir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu denetimin yapılabilmesi için, makul bir sebebin bulunması gerekir.

Trafik kazasına karışmamış sürücünün, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında olup olmadığının tespiti amacıyla denetime tabi tutulmayı salt kabul etmemesi, **idari yaptırım** uygulanmasını gerektirmektedir⁴⁹⁸.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, yapılan denetim sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında olduğu tespit edilen sürücü hakkında, TCK'nın 191. maddesinde tanımlanan suç sebebiyle **adli soruşturma** başlatılması gerekir. Bu sürücüye **ayrıca idari yaptırım** uygulanacaktır⁴⁹⁹.

rülmekle birlikte; düşük konsantrasyondan itibaren alkol düzeyinin artışı ile paralel olarak artan derecelerde **gevşeme, dikkat azalması, cesaretlenme, çevresel uyarıların algılanmasında yavaşlama, göz ve beyin arasındaki iletişim süresinde uzama, algılanan çevresel uyarıların beyinde işlenmiş veriler haline dönüşmesinde gecikme** dolayısıyla **uyaranlara karşı reaksiyon zamanında uzama, beyinciğin etkilenmesi suretiyle denge ve koordinasyonun olumsuz yönde etkilenmesi, ani karar verebilme, direksiyon ve fren kontrolü gibi birden fazla hareketi bir arada yapabilme kabiliyetinde azalma, uyarıların erken fark edip doğru tepkiler verme, istemli göz hareketleri, gözün takip yeteneği, karanlığa adaptasyon, hız ve mesafe tayini gibi becerilerde olumsuz yönde etkilenme, istemsiz göz hareketlerinin ortaya çıkması, uykuya meyil** gibi belirtilerin oluştuğu, bu durumdaki bir sürücünün risk alma eğiliminin arttığı, **sürüşle ilgili becerilerinde azalma** olduğu ve **kaza ihtimalinin arttığı**nın bilimsel olarak kabul edildiği belirtilmiştir.

Nitekim trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından verilen hükümlerin temyiz incelemesini yapan **Özel Dairece, bilimsel verilere dayanarak 100 promilden yüksek olarak belirlenen alkol düzeyinin, kişinin melekelerini zayıflatacağı ve güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceği kabul edilmek suretiyle, 100 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanan sanıkların trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği** sonucuna ulaşılmıştır (Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 18.01.2012 gün ve 2011/6233 esas-2012/348 karar; 14.03.2012 gün ve 2011/13259 esas-2012/7188 karar; 26.03.2012 gün ve 2011/11191 esas-2012/8282 karar sayılı kararları).

Trafik görevlilerince yapılan alkolmetre ölçümüne göre sanığın trafik kazasının hemen sonrasında 155 promil alkollü olduğunun tespit edilmiş olması, kolluktaki savunmasında içtiği biraların kendisini sarhoş edeceğini tahmin edemediğini, alkollü araç kullandığından dolayı pişman olduğunu belirtmesi ve güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş olduğunu gösterir şekilde bir başkasının aracına arkadan çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazasına neden olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığa isnat edilen, **alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma** suçu **tüm unsurlarıyla oluşmuş**“tur: CGK, 8.10.2013, E. 2012/2-1426, K. 2013/417. Ayrıca bkz. Yargıtay CGK, 28.11.2019, E. 2015/15-489, K. 2019/682.

⁴⁹⁸ Bu sürücülere “**2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.**” (2918 s. K, m. 48, f. 9).

⁴⁹⁹ Bu sürücülere “**3.600 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır.**” (2918 s. K, m. 48, f. 8).

“Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler Sağlık Bakanlığınca,

C. Meşru Savunma

Meşru savunma (*meşru müdafaa*), bir kimsenin, kendisini veya başkasını hedef alan bir tecavüz, saldırı karşısında, savunma amacına matuf olarak ve bu saldırıyı defedecek ölçüde kuvvet kullanmasını ifade eder⁵⁰⁰.

Meşru savunma halinde, gerçekleşmekte olan bir saldırıyı defetmek amacına yönelik olarak işlenen fiil, dış görünüşü itibarıyla bir suç oluşturmaktadır. Ancak, bu fiil, gerçekleşmekte olan bir tecavüzü uzaklaştırmak amacıyla işlenmektedir.

Bütün mevzu hukuk sistemleri, meşru savunma halinde gerçekleştirilen fiil dolayısıyla kişiye ceza verilmeyeceğini kabul etmektedirler. Ancak, meşru savunma halinde bulunan kişiye ceza verilmemesinin teorik izahında iki temel görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden birine göre, bir saldırıyla karşı karşıya kalan kişinin meşru savunma fiili, bu kişi açısından bir mazeret sebebi oluşturmakta ve kişinin sadece kusurluluğu üzerinde etkili olmaktadır⁵⁰¹. Diğer grup görüşe göre, meşru savunma bir hukuka uygunluk sebebi oluşturmaktadır⁵⁰².

765 s. Kanunun 49. maddesinde (bent 2) olduğu gibi, yeni TCK'nın 25'inci maddesinin birinci fıkrası metninde meşru savunma durumunda faile sadece ceza verilmeyeceği belirtilmiştir; ancak, faile ceza verilmemesinin sebebi konusunda bir açıklık bulunmamaktadır⁵⁰³:

«Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl

usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitime; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.» (2918 s. K, m. 48, f. 11).

Önemle belirtmemiz gerekir ki, bu hükümlere “göre geri alınan sürücü belgesinin iade edilebilmesi için; ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla (2918 s.) **Kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması**; uyuşturucu veya uyarıcı madde alması nedeniyle sürücü belgesi geri alınanların ayrıca sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi **şarttır.**” (2918 s. K, m. 48, f. 13).

⁵⁰⁰ Yargıtay, meşru savunmayı şu şekilde tanımlamaktadır:

«Yasal savunma; failin ağır ve haksız bir saldırıyı kendisinden veya başkalarından uzaklaştırmak amacı ile gösterdiği zorunlu tepkidir.»: CGK., 22.5.1995, 1-80/158 (YKD, Ağustos 1995, sh: 1293 vd.).

⁵⁰¹ EREM, Genel Hükümler II, sh. 3, 24, 25. Bu görüşü benimseyen diğer yazarlar hakkında bkz. ÖZEN, Muharrem: *Türk Ceza Hukukunda Meşru Savunma*, Ankara, 1995, sh. 49 vd.

⁵⁰² ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 208; ÖZEN, Meşru Savunma, sh. 69. Bu görüşü benimseyen diğer yazarlar hakkında bkz. ÖZEN, Meşru Savunma, sh.59 vd. Meşru savunmanın hukuki niteliği hakkında ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. ÖZAYDIN, Özdem: *Notwehr und Notstand im deutsch-türkischen Rechtsvergleich*, Baden-Baden, Bern, 2013, sh. 29 vd.

⁵⁰³ Buna rağmen, doktrinde, 765 s. TCK'nın 49. maddede sayılan cezasızlık hallerinin hepsinin, hukuka uygunluk sebepleri olduğu görüşü hakimdir (Bkz. ÖZEN, Meşru Savunma, sh. 19).

ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.»

Bir saldırıyla karşı karşıya olan kişi, tabiatı gereği olarak, bu saldırıyı defetme yönünde bir tepkide bulunur ve kendisini, bu tepki cümlesinden olarak gerçekleştirdiği fiil açısından *haklı* hisseder.

Kanımızca, meşru savunma halinde, şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen fiil, *hukuka uygundur* ve dolayısıyla, herhangi bir sorumluluğu gerektirmez. Çünkü, gerçekleşmekte olan bir saldırıya maruz kalan kişi, bu tecavüzü uzaklaştırmak amacıyla hareket etmektedir. İşte bu amaç, icra edilen fiili, saldırıyı defedecek ölçüde olması şartıyla, hukuka uygun hale getirmektedir⁵⁰⁴.

Meşru savunmada bulunan kişinin meşru savunma şartlarına uygun olarak gerçekleştirdiği fiil, muaheze edilmesini, kınanmasını, ayıplanmasını gerektirmez; aksine, meşru savunmada bulunan kişi aynı zamanda insanlarda hukuk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmuş olur⁵⁰⁵.

Nitekim yeni TCK'nın 25'inci maddesinin meşru savunmayı düzenleyen birinci fıkrasının gerekçesinde, meşru savunmanın "*bir hukuka uygunluk nedeni*" olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Yeni CMK'nın 223'üncü maddesinde, beraat kararının verilebileceği haller, ikinci fıkra; kusurun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilebileceği haller ise, üçüncü fıkra; tek tek gösterilmiştir. Bu fıkralar hükümleri de göz önünde bulundurulduğunda mevzuatımızca meşru savunmanın bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edildiği açık bir şekilde görülmektedir.

⁵⁰⁴ Nitekim, meşru savunma halinde işlenen fiil dolayısıyla kişi hakkında *beraat* kararı verilmektedir: CGK., 6.2.1973, 407/88 (Özen, Meşru Savunma, sh. 153, dn. 39). ÖZAYDIN, sh. 234 vd.

⁵⁰⁵ «Meşru savunma, bir kimsenin ağır ve haksız bir tecavüzü kendisinden veya başkasından uzaklaştırmak amacı ile gösterdiği zorunlu tepkidir.

Meşru savunma halinde işlenen fiil, *hukuka uygundur* ve bunun sebebini hukuk düzeninin hakkın tecavüze uğramasına izin vermiyeceği esasında aramak gerekir. Hukuk, esasen haksızlığı yenmek, adaletsizliği, saldırıları yasaklamak amacını güder; hukukun yaşaması, muzaffer olabilmesi için, haksızlıkla, saldırılarla savaşılmaması gereklidir. Hukuku korumak, haksızlığı yenmek için savaşılan kimsenin hareketini ise hiçbir hukuk düzeni hukuka aykırı olarak kabul edemez. Bu sebeptendir ki, savunmanın meşruluğu, hukukun kendi görev kavramlarından doğmaktadır.

Kaldı ki, savunmada bulunmak; her varlığın ve bu arada insanın kendisini ve mensup olduğu türü korumak tepkisinin sonucudur. Bu tepki aynı zamanda toplumun yararlarına da uygundur. Kuvvet kullanmak suretiyle haksız bir saldırıyı uzaklaştıran kimse, yalnız ahlâk bakımından ayıplanması mümkün bulunmayan bir hareket yapmış, hukuk için savaşılmış olmakla kalmaz; fakat topluma da hizmet etmiş aynı zamanda sosyal savunmaya katılmış olur.

Şu halde, meşru savunma halinde işlenen fiil, hukuka uygundur ve bu halde suçun hukuka aykırılık unsuru bulunmamaktadır ve bu sebeple faile ceza vermek imkansızdır.»: CGK., 3.6.1985, 185/331 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, 1. bası, sh. 670-674). Ayrıca bkz. CGK., 15.2.2000, 1-22/27 (Kaban/Aşaner/Güven/Yalvaç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara, 2001, sh. 57-60), CGK., 23.3.1999, 1-46/56 (Kaban/Aşaner/Güven/Yalvaç, sh. 60-62).

Meşru savunmadan söz edebilmek için, bir *saldırımın* (*tecavüzün, taarruzun*) varlığı gereklidir.

Saldırımın filhal yani halen mevcut olması gerekir. Yeni TCK'nın ifade biçimine göre, saldırının “*gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırı*” olması gerekir.

«Saldırımın halen varlığını geniş manada anlamak ve başlayacağı artık muhakkak olan bir saldırıyı başlamış, keza bitmiş olmasına rağmen tekrardan korkulan bir saldırıyı da henüz sona ermemiş saymak zorunludur. Örneğin elindeki bıçağı uyarıya rağmen bırakmayan bir kimse saldırıya başlamış sayılacağı gibi, hasmını yere yıkan kişinin saldırısını daha ileri derecelere götüreceği anlaşıyorsa, saldırı sona ermiş sayılamaz. Henüz başlamamış saldırı tehlike teşkil edebilir ve sona eren bir saldırının tekrar edilmesi tehlikesi de bulunabilir.»⁵⁰⁶

Saldırı tamamlanmış ise, artık meşru savunmadan söz edilemez⁵⁰⁷.

Bazı saldırılar, mahiyeti gereği olarak, meşru savunmaya elverişli değildir. Örneğin bir insana vaki sövme fiili karşısında meşru savunmada bulunulabileceğini söylemek güçtür.

Saldırımın cebir ve şiddet içermesi zorunlu değildir⁵⁰⁸. Hatta, tecavüz, ihmali davranışla da gerçekleşebilir⁵⁰⁹.

⁵⁰⁶ CGK., 27.5.1991, 1-145/172 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, 1. bası, sh. 631).

⁵⁰⁷ «Sanık M.A. ile resmen evli olmayan sanık Z. ye değişik günlerde cinsel tacizde bulunan maktulün, olay günü Z. nin yalnız olduğu sırada evi içine alkollü vaziyette girerek onunla cinsel ilişki kurmak istediği; kabul etmeyip direnmesi üzerine ona sarılıp elbisesinin yırtılmasına neden olduğu; zorla tecavüz edilmeyi önlemek için Z. nin maktulle ilişkiye gireceğini beyan ederek onu kısmen sakinleştirdiği; maktulün ısrarla evi terk etmeyip her an zorla ırza tecavüzünü sürdürebilecek konumda iken, Z. nin bir fırsatını bularak av tüfeği ile maktule iki el ateş edip, 15 gün iş ve güçten kalacak şekilde iki yerden yaraladığı; işten dönen ve maktulün ev içinde olduğundan habersiz sanık M.A. nın silah sesleri üzerine içeriye girdiğinde maktulle sanık Z. yi mücadele ederken gördüğü; maktulün kollarından sarmak suretiyle tuttuğu bu sırada Z. nin odayı terk etmesi ve aldığı yara sonucu saldırısı son bulan ve etkisiz halde bulunan maktule oda içinden temin ettiği bıçakla birden çok vurarak öldürdüğü anlaşılmakla;

a- Sanık Z. nin evde yalnızken maktulden gelen ırza yönelik ve derhal durdurulması gereken saldırıyı önlemek için ona ateş ettiğinin kabulü ile TCK'nın 49/2. maddesi uyarınca uygulama yapılması gerektiği;

b- Sanık M.A. nın ise, saldırısı son bulan maktule kapıldığı ağır ve haksız tahrikten etkisi ile bıçakla vurup onu öldürdüğü ve fiilin TCK'nın 448, 51/2. maddelerine uyduğu gözetilmeden hüküm kurulması kanuna aykırıdır.»: 1. CD., 8.12.1998, 3262/3834 (YKD, Mart 1999, sh. 402 vd.).

«Maktulün hasmını öldürdükten sonra uzaklaşırken sanıkların kendisine yaklaşıp öldürdükleri anlaşılmış olduğundan, olayda hemzamanlık unsurunun mevcut olmadığı düşünülmeyen, TCK'nın 448, 51/2. maddelerine göre ceza tayini gerekirken, meşru savunma halinin kabulü bozmayı gerektirmiştir.»: 1. CD., 30.6.1977, 2338/2333 (Özen, Meşru Savunma, sh. 78, dn. 24).

⁵⁰⁸ ÖZEN, Meşru Savunma, sh. 75.

⁵⁰⁹ Bkz. İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 3. bası, Ekim 2004, sh. 134; ÖNDER, Özel Hükümler II, sh. 209: Meselâ, tutukluluk kararı

Saldırı, niteliği gereğince *haksız* olan bir *davranıştır*. Bir fiilin saldırı, tecavüz niteliğinde olup olmadığı ve dolayısıyla haksızlık teşkil edip etmediği değerlendirilirken, hukuk düzeni bir bütün olarak dikkate alınmalıdır.

Ancak, 765 s. Kanunun 49. maddesinin meşru savunmayı düzenleyen ikinci bendinde saldırı anlamına gelen “*taarruz*” ibaresinden sonra ayrıca “*haksız*”lıktan söz edilmişti. Aynı şekilde yeni TCK’nın 25. maddesinin birinci fıkrasında “*haksız bir saldırı*” ibaresi kullanılmıştır. Bu ifade biçiminden, haksız olmayan bir saldırının da var olabileceği gibi bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Çünkü, bir davranış, niteliği gereğince haksızlık ifade etmiyorsa, bunu bir saldırı olarak kabul etmek mümkün değildir.

Bu itibarla, madde metninde *saldırı* (veya “*taarruz*”) ibaresi kullanıldıktan sonra ayrıca “*haksız*”lıktan söz edilmesinin meşru savunma halinde bulunan kişinin amacı açısından bir önemi bulunmaktadır. Başka bir deyişle, meşru savunma halinde bulunan kişi, kendisine veya bir başkasına karşı işlenen fiilin bir tecavüz teşkil ettiğini ve dolayısıyla, **haksız olduğunu bilmelidir**. Kişi, bu bilincin yanı sıra, söz konusu **tecavüzü defetmek amacıyla** savunma hareketlerini gerçekleştirmelidir.

Meşru savunma açısından, saldırının mutlaka bir insandan kaynaklanması gerekir. Zaten, haksız bir davranış olan tecavüzden söz edebilmek için, bunun mutlaka bir insanla ilişkilendirilmesi gerekir. Bir hayvana izafe edilen davranış, haksızlık olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla, hayvandan kaynaklanan “tecavüz”den söz edilemez⁵¹⁰. Ancak, bir insan tarafından hayvanın başkasına saldırıya kışkırtılması durumunda, bir tecavüz vardır ve bu tecavüz, kışkırtan kişiye izafe edilen haksız davranıştır⁵¹¹.

Ancak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin meselâ akıl hastası veya yaş küçüğü olması gibi bir sebeple kusur yeteneğinin olmaması, önemli değildir⁵¹².

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin de belli olması gerekir. Çünkü, meşru savunma, ancak saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı mümkündür.

Saldırıya uğrayan kişi, kendi hareketiyle saldırıyı tahrik etmiş olabilir. Kanımızca, bir kimsenin saldırıyı kendi haksız davranışıyla tahrik etmesi durumunda

kaldırılan ve bu nedenle “belirli bir süre sonra serbest bırakılması gereken şahsı süre geçtiği halde serbest bırakmayan kişiye karşı meşru savunma mümkündür.”

⁵¹⁰ Her ne kadar örneğin köpeğe izafe edilen davranışlar günlük dilde “saldırı” olarak ifade edilmekte ise de; bu davranışlar, hukuki anlamda fiil olarak nitelendirilemezler ve dolayısıyla, bu davranışların haksızlığından veya hukuka uygunluğundan bahsedilemez.

⁵¹¹ Bkz. İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 2. bası, sh.; SOYASLAN, Genel Hükümler, sh. 406.

⁵¹² Aksi fikir için bkz. İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 3. bası, sh. 137.

dahi, bu saldırıya karşı meşru savunmada bulunabileceğini kabul etmek gerekir. Çünkü, tahrikin varlığına rağmen, gerçekleştirilen fiil, tecavüz ve dolayısıyla, haksızlık özelliğini muhafaza etmektedir⁵¹³.

Ancak, meşru savunma halinde bulunan kişinin hareketi hukuka uygun olduğu için, bu kişiye karşı meşru savunmadan söz edilemez.

Saldırı, kişinin hayatına, vücut bütünlüğüne veya sahip bulunduğu herhangi bir hukuki değere yönelik olabilir. Ancak, belirtmek gerekir ki; 765 s. Kanunun 49. maddesinin meşru savunmayı düzenleyen ikinci bendinde “nefse” veya “ırza” yönelik tecavüzler açısından meşru savunma kabul edilmişti. “Nefis” ve “ırz” kelimeleri gerek doktrinde gerek Yargıtay uygulamalarında⁵¹⁴ geniş yorumlan-

⁵¹³ «Sanığın eyleminin savunmaya yönelik olduğunu kabulde zorunluluk bulunduğu ve olayın başlangıcında kendisinden sadır olan keyfi atışın nefesine yönelik saldırıyı def hakkını yok edemeyeceği tartışma kaldırmayacağından, TCK'nın 49. maddesi mucibince ceza tertibine yer olmadığına ve beraatine karar verilmesi gerekirken; yazılı biçimde mahkumiyetine hükmedilmesi, yasaya aykırıdır.»: 1. CD., 28.12.1995, 3894/3990 (YKD, Mart 1996, sh. 470 vd.).

«Küfreden, daha sonra küfredilen kişilerin saldırısına uğradığına göre, koşullarının varlığı halinde yasal savunma içinde bulunabilir.»: CGK., 18.10.1990., 1-158/178.

«Taarruza hedef olan kimsenin kendi şahsi kusuru ile taarruza sebebiyet vermiş olması, savunmanın meşruluğunu ortadan kaldırmaz. Meşru savunmanın kabulü için, diğer şartlarla birlikte “saldırıya karşı savunmada zaruret” bulunması lazımdır. Bu zaruretin, gerek savunma ile ona sebebiyet veren saldırı arasındaki nisbet ve gerekse saldırıyı başka suretle bertaraf etmenin mümkün olup olmadığı bakımlarından incelenmesi icap eder. Bu şartın en önemli noktası, failin uğradığı saldırıdan başka suretle kurtulmak imkanı olup olmadığı başka deyimle failin karşılaştığı saldırı dolayısıyla başka türlü hareket imkanı bulunup bulunmadığı keyfiyettir.»: CGK., 31.11.1983, 354/16 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, 1. bası, sh. 677/678).

⁵¹⁴ Yargıtay da konut dokunulmazlığını ihlâl niteliğindeki bir davranışı, nefse tecavüz olarak mütalâa etmiştir:

«Olayda müşteki ve yanındakiler sanığın konut dokunulmazlığına karşı haksız bir saldırıda bulunmuşlardır. TCK'nın 49. maddesinde “Gerek kendisinin, gerek başkasının nefesine veya ırzına vukubulan haksız bir taarruzu filhal defî zaruretinin bais olduğu mecburiyetle ... işlenen fillilerden dolayı faile ceza verilemez” hükmü (mevcuttur). O halde meşru savunmadan söz edebilmek için haksız bir saldırı olmalı ve bu saldırı kişinin veya başkasının nefesine veya ırzına yönelik bulunmalıdır. Saldırı ise, hukukça korunan bir menfaatin çiğnenmesi veya tehlikeye konulmasıdır. Burada(ki) “nefis” kavramını açmak gerekirse; mehz İtalyan Ceza Kanununda “kendisi” kavramı yerine kullanıldığını görmekteyiz. “Kendisi” kavramı kişinin, vücut tamlığı, kişi güvenliği, sağlığı, kişisel özgürlüğü, şeref ve onur duyguları gibi kavramları kapsamaktadır. ...

Sanık, konut dokunulmazlığını geceleyin bozan ve bunda direnen müşteki ve yanındakilere tabanca çekerek evini terketmelerini sağlamıştır. TCK'nın 193. maddesinde öngörülen suç hürriyet aleyhinde işlenen cürümler arasında düşünülmüş ve konut dokunulmazlığı kişiler için bir çeşit hürriyet niteliğinde görülerek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olarak kabul edilmiştir. Maddenin özünde konutun fizik varlığı ve mal niteliği değil, kişilerin güvenlik içinde barınabilecekleri bir yuva özelliği öngörülerek bu kavramın güven ve huzuru korunmak istenmiştir...

(Bu durum) karşısında; konut dokunulmazlığı saldırıya uğrayan sanığın bunu koruma ve sağlamaya yönelik hareketleri, TCK'nın 49. maddesinde öngörülen meşru savunma sınırları içinde kalmaktadır.»: CGK., 28.12.1987, 8-524/695 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, 1. bası, sh. 634/635).

maktadır. Bu kavramlar geniş yorumlanmak suretiyle *kişilik haklarına yönelik bütün saldırılar* açısından meşru savunmanın varlığı kabul edilmiştir⁵¹⁵.

Buna karşılık, malvarlığına vaki tecavüzü defetmek amacıyla işlenen fiilin, Türk Ceza Kanununda meşru savunma olarak kabul edilip edilmemesi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Meşru savunmayı genel olarak düzenleyen 49. maddenin ikinci bendi hükmünde malvarlığına yönelik tecavüzlere karşı meşru savunma kabul edilmemiştir.

Yeni TCK'da ise, meşru savunmanın kabulü için saldırının *herhangi bir hakka* yönelik olması yeterli görülmüştür⁵¹⁶.

Tecavüzün, üçüncü kişiye karşı olması durumunda da meşru savunma kabul edilmiştir⁵¹⁷.

Keza Yargıtay, başka kararlarında kaçırılmak istenen kişinin kurtarılmasına yönelik fiilleri de meşru savunma olarak kabul etmiştir:

«Mağdure G.A'nın maktul M ve babası B tarafından kaçırılmak istenmesi ve binnetice ırzına karşı yapılan haksız saldırıyı hemen savuşturmak zorunluluğu içerisinde, başka kurtuluş çarelerinin de kalmadığından M'nin (kaçırılmak istenen G.A'nın babası ve dayısı olan) iki sanık tarafından öldürül(mesi karşısında); eylemlerinin TCK'nın 49/2. maddesi kapsamı içerisinde düşünülmesi gerekirken “zorla ırza geçmeye teşebbüs olmayıp kaçırmaya teşebbüs olduğundan” ve TCK'nın 49/2. maddesindeki bir şahsın vücut tamamıyetinin savunmasının bahse konu olduğu ve yine “nefis” ve “ırz” tabirlerinin meşru savunmanın şumülünü daraltmak için değil, belirtmek ve binnetice geniş manada kabul edilmesi icap ettiği göz önünde tutulmuyarak; isabet bulunmayan bazı düşüncelerle TCK'nın 51/2. maddesinin uygulanması yasaya aykırıdır.»: 1. CD., 29.2.1972, 716/869 (Özen, Meşru Savunma, sh. 109, dn. 115).

«Sanı(k), olay gecesi tarladan evine döndüğü sırada kaçırılmak suretiyle namusu tehlikeye maruz bırakılan ablasını, maktulün bu haksız taarruzundan kurtarmak maksadı ile tabanca ile ateş ederek onu öldürdüğün(e) ... göre; fiilin, TCK'nın 49. maddesinin 2. bendinde yazılı şartlar içinde işlendiği anlaşılmıştır: CGK., 6.5.1974, 83/262 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, 1. bası, sh. 651).

⁵¹⁵ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZEN, Meşru Savunma, sh. 95 vd.

⁵¹⁶ Bazı yazarlar, yeni TCK'da malvarlığına yönelik saldırılara karşı da meşru savunmanın kabul edilmesinin “tartışma” yaratabileceğini ileri sürmektedirler (YARSUVAT/BAYRAKTAR ve diğerleri, sh. 295).

Tezcan/Ertem/Sancakdar'ın da benimsediği bir görüşe göre; “örneğin mülkiyetin korunması amacıyla adam öldürmenin iç hukuka uygun sayılması durumunda Sözleşme'ye (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine) aykırılık söz konusudur.” (TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/SANCAK-DAR, Oğuz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, 2. bası, Ankara, 2004, sh. 216). Bu endişe bir yanılgıya dayanmaktadır. Bu yanılgı da şudur: Meşru savunma için, savunma amacıyla gerçekleştirilen fiil sonucunda saldırganın her halde öldürülmesi söz konusudur. Halbuki aşağıda da vurgulanacağı üzere, savunma amacına yönelik olarak gerçekleştirilen fiilin saldırıyı etkisiz kılacak ölçü ve oranda olması gerekir. Bu ilke göz önünde bulundurulduğunda söz konusu endişenin gereksiz olduğunu düşünmekteyiz.

⁵¹⁷ «Sanı(k), olay gecesi tarladan evine döndüğü sırada kaçırılmak suretiyle namusu tehlikeye maruz bırakılan ablasını, maktulün bu haksız taarruzundan kurtarmak maksadı ile tabanca ile ateş ederek onu öldürdüğün(e) ... göre; fiilin, TCK'nın 49. maddesinin 2. bendinde yazılı şartlar içinde işlendiği anlaşılmıştır: CGK., 6.5.1974, 83/262 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, 1. bası, sh. 651).

Gerçekleştirilen *savunma* hareketinin zorunlu olması, yani maruz kalınan tecavüzü başka türlü defetme imkanının bulunmaması gerekir⁵¹⁸. Tecavüz karşısında bulunan kişinin bu tecavüzden kendisini korumaya yönelik bir gayret içinde olması gerekirse de, kaçması kendisinden beklenemez⁵¹⁹.

Gerçekleştirilen *savunma* hareketinin, maruz kalınan tecavüzü defedecek ölçüde olması gerekir^{520,521}. Aksi takdirde savunmada sınır aşılmış olur⁵²².

⁵¹⁸ Ayrıntılı bilgi için bkz ÖZEN, Meşru Savunma, sh. 112 vd.

⁵¹⁹ «Yasal savunmada sanığa kaçma mükellefiyeti yükletilemeyeceği gibi, sanıktan kaçarak kurtulması istenemez. Failin kaçma olanağının bulunup bulunmadığı da dikkate alınmaz.»: CGK., 8.4.1997, 1-59/83 (Kaban/Aşaner/Güven/Yalvaç, sh. 70/71).

⁵²⁰ Ancak, belirtmek gerekir ki klasik anlayışta, saldırı ile savunma arasında “oran” bulunması gerektiği görüşü hakimdir: “Saldırıya uğrayan haktan çok üstün bir hakka zarar verilmişse, savunmada zorunluluk sınırı aşılmış olaca”ktır (ÖZEN, Meşru Savunma, sh. 120 vd. [123]) Kanımızca doğru değildir. Önemli olan, savunma sadedinde gerçekleştirilen fiilin, tecavüzü defedecek ölçüde olmasıdır. Bu ölçüye riayet edildikten sonra, tecavüze uğrayan hukuki değerle, bu tecavüzü defetmek için kendisine zarar verilen değer arasında bir oranın bulunması gerekmez. Bu itibarla, malı gaspedilmekte olan kişinin malını kurtarmak için gasibin yaralanmasına ve hatta ölümüne sebebiyet vermesi durumunda da, meşru savunmanın varlığını kabul etmek gerekir.

⁵²¹ «Saldırganların bir kızı kaçırdıklarını görüp durmalarını ihtar eden ve sonra fiile engel olmak için havaya ve faillerin ayaklarına ateş açan ve bu arada saldırganın da ölümüne sebep olan kimse üçüncü şahıs lehine meşru savunma halinde kabul edilmelidir.»: 1. CD., 30.5.1970, 969/2903 (Özen, Meşru Savunma, sh. 136).

⁵²² «Sanık ve eşi, evlerinin zemin katındaki odalarında gece saat 23.30 sıralarında soyunmuş vaziyette seviştikleri sırada oda zemininden 80 cm. yükseklikteki perdesi aralıklı pencereden kendilerini bir insan karartısının gözetlediğini görmüşler; sanık kendilerini gözetleyenin gitmesi için ışığı kısık gaz lambasının ışığını açmış; gitmeyince öksürmüş; bu şahsın pencereden ayrılmaması üzerine yatağın altındaki tabancasını alarak pencere perde aralığından bir el ateş edip, maktulü öldürmüştür.

Bu şekilde oluşan eylemde, sanığın pencere önünde gördüğü ve insan olduğunu anladığı karartıya tabancayla perdede iz bırakmayacak biçimde, ya perde aralığından, ya da perdede aralayarak, başa nişan almak suretiyle ateş ettiği anlaşılmaktadır.

Sanığın çok yakın mesafeden öldürücü nitelikteki silahını maktulün başını hedef almak suretiyle ateşlediği, bu itibarla öldürme kastıyla davrandığı görülmektedir.

Hal böyle olunca, mahkemenin suç niteliğine ilişkin kabulü ve TCK’nın 448. maddesiyle hüküm kurulması yasaya uygun bulunmaktadır.»: CGK., 6.4.1981, 1-5/117 (Savaş/Mollamahmutoğlu IV, 3. bası, sh. 4801/4802).

Kanımızca, bu kararın gerekçesi tutarlı değildir. Karara konu teşkil eden olayda maktul tarafından fail ve eşinin özel hayatının mahremiyetine yönelik bir tecavüz mevcuttur. Failin bu tecavüzü defetmek için ve defedecek ölçüde fiiller icrası, hukuka uygun addedilmelidir. Ancak, karara konu teşkil eden olayda, kabul edildiği üzere, sanık, maktulün kafasını hedef alarak ve öldürmek kastıyla hareket etmiştir. Bu itibarla savunmada sınırı kasten aşmış olduğunu kabul etmek gerekirdi. Yargıtay’ın bu olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yönelik düşüncesi, failin meşru savunma sınırını korku ve panik etkisi olmaksızın, yani kasten aşılmış olması dolayısıyla doğrudur.

Keza, Yargıtay’ın şu kararına konu teşkil eden olayda, aslında bir saldırı mevcuttur. Sorun, bu saldırı karşısında meşru savunma sınırının aşıp aşılmadığı noktasında olmasına rağmen; Yargıtay’ın olayda bir saldırının mevcut olmadığı yönündeki görüşü doğru değildir:

Kişinin, kendisine veya başkasına yönelik **bir tecavüzün varlığının bilincinde olması** ve bu **tecavüzü defetmek amacıyla hareket etmesi** gerekir (*meşru savunma bilinci*)⁵²³.

Meşru savunma halinde bulunan kişi, bu hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarının gerçekleştiğinin bilincinde olmalıdır. Yani, bu şartlar konusundaki bilgi, kast kapsamında mütalâa edilen bilgidir⁵²⁴.

Bu itibarla, işlediği fiil açısından meşru savunmanın maddi şartları esasen gerçekleşmediği halde, bu şartların gerçekleştiği zannıyla hareket eden kişinin işlediği suç açısından kastının varlığından bahsedilemez^{525,526}.

«Şehirden 2,5 km. uzakta meskun olmayan bir yerde, yaşlı annesi ve küçük çocuğu ile oturmakta bulunan sanığın evinin kapısına gündüzleyin bir mektup bırakan ölen, geceleyin saat 24 sıralarında evin önüne gelerek, kapı ve penceresine taş atmak suretiyle, sanığın kapıya çıkmasını sağlayarak onunla sevişmek istediğini belirtmiş, bu hususta ısrarlı olduğunu vurgulamıştır. Bunun üzerine av tüfeği ile dışarı çıkan sanık, ölenin üzerine doğru yürümeye başlayınca ölen geri geri çekilerek bir ağacı kendisine siper etmek isterken, sanık ateş ederek onu öldürmüştür.

Bu oluştta, ölenden gelen bir saldırı bulunmamaktadır. Ölen, konuta girme teşebbüsünde bulunmadığı gibi, sanığın ırzına yönelik fiili bir saldırısı da söz konusu değildir. Kaldı ki, üzerine herhangi bir saldırı veya savunma silahı bulunmayan ölen, sanığın tüfekle dışarı çıkması üzerine geri çekilerek kaçmaya çalışmıştır. O halde, başlayacağı muhakkak olan bir saldırı olasılığı da görülmemektedir.»: CGK., 1.6.1992, 1-154/178 (Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, Genel Hükümler, sh. 671/672).

Halbuki bu karara konu teşkil eden olayda sanığın şerefine ve hatta konut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı durumu mevcuttur.

⁵²³ Gerek doktrinde gerek Yargıtay kararlarında kabul gören saldırının geniş yorumlanması gerektiği yönündeki düşünce, bu görüşümüzü haklı kılmaktadır.

⁵²⁴ ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 152.

⁵²⁵ Bkz. ÖZEN, Meşru Savunma, sh. 142 vd.

⁵²⁶ Çeşitli Yargıtay kararlarında meşru savunmanın şartları şu şekilde özetlenmiştir:

"5237 sayılı Kanunun sisteminde; "meşru müdafaa, hakkın kullanılması, kanunun emrini ifa ve ilgilinin rızası" şeklinde başlıca dört hukuka uygunluk nedenine yer verilmiştir. Hukuka uygunluk nedenlerinden birinin bulunması, eylemin suç olmasını engelleyeceğinden, fail hakkında beraat kararı verilmesi gerekecektir. Buna karşılık "sınırın aşılması" bir hukuka uygunluk nedeni değil, 27. maddenin birinci fıkrasındaki hal itibarıyla kusurluluğu azaltan, ikinci fıkrasındaki durum itibarıyla ise kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerden birisidir. Başka bir deyişle hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın kast olmaksızın aşılması durumunda "beraat" değil, 27. maddenin birinci fıkrasına göre indirimli ceza veya ikinci fıkra uyarınca "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmelidir. Bu husus, 5271 sayılı Kanunun 223. maddesinden de açıkça anlaşılmaktadır.

Şu halde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 27. maddesinin birinci fıkrasının uygulanabilmesi için; öncelikle ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir neden söz konusu olmalıdır. Failin, sınırları "kast olmaksızın aşması" da ikinci şarttır. Dolayısıyla 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 50. maddesinden farklı olarak sınırın kasten aşılması durumunda bu fıkra uygulanamayacaktır. Yine 765 sayılı Kanundaki durumdan farklı olarak, 5237 sayılı TCK'nda hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmemiş olsa da ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerden olan "zorunluluk hali" için de 27. maddenin birinci fıkrasının uygulanma imkanı bulunmaktadır.

D. İlgilinin Rızası

İlgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni, 765 s. Kanunun aksine, yeni TCK'da açık bir şekilde düzenlenmiştir:

“Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.” (m. 26, f. 2)

Kanunda ayrıca çeşitli suç tanımlarında “rızası olmaksızın” (m. 99, f. 1; m. 101, f. 1; m. 132, f. 3; m. 245, f. 1) veya “rızası olmadan” (m. 133, f. 2; m. 141, f. 1; m. 163, f. 2) ibareleri kullanılmıştır. Rızanın yokluğu, ilgili suçun maddi unsurları bağlamında mütalaa edilmesi gereken bir *olumsuz unsur* oluşturmaktadır: *Suçun olumsuz unsurları teorisi*⁵²⁷. Bu teoriye göre, suçun kanunî tarifinin fonksiyonu, sadece suça ilişkin maddi ve manevi unsurların belirlenmesinden ibaret değildir. Bu tarif, aynı zamanda fiilin hukuka aykırılık teşkil ettiği hususundaki bütün unsurları da kapsamaktadır. Bu suretle, bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları, suçun olumsuz unsurları olarak mütalâa edilmektedir. Ancak bu şartların gerçekleşmemesi halinde işlenen fiil, hukuka aykırılık vasfını haiz olacaktır⁵²⁸. Bu itibarla, işlenen suç açısından hukuka uygunluk sebeple-

...

... S'nin, öncesinde kendisini telefonla tehdit eden, dükkanına gelerek tehditlerini yineleyen, bir süre sonra bu kez yeğeni ile birlikte ellerinde ucu topuz şeklindeki sopalarla gelen, kendisinden fiziki olarak daha güçlü yapıdaki M ile yeğenin saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla imal edilmiş sopalı saldırısına uğradığı; kendisini savunabilmek amacıyla eline aldığı sopa düştürüldükten sonra kafasında dört ayrı yerde kırık oluşacak şekilde yaralandığı; hareket kabiliyeti oldukça sınırlı bulunan bir yere sırt üstü yatırılarak saldırının devam ettirildiği; ancak bu aşamadan sonra elinde olmasına rağmen henüz kullanmadığı **silahını yakın mesafeden hedef gözetme imkanı bulunmadan ateşlediği** ve M'yi biri hayati tehlike oluşturacak, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı; M ile yeğenin bu atışlardan sonra dahi sanığa vurmaya devam ettikleri; ancak S'nin kardeşinin olay yerine gelerek av tüfeğiyle M'ye ateş etmesi üzerine saldırılarına son vermek zorunda kaldıkları; **ilk haksız hareketin M'den kaynaklanmasıyla başlayan, devam eden ve artarak devam etmesi de muhakkak olan haksız saldırıyı, o andaki hal ve şartlara göre önce M ve yeğenin saldırıda kullandıkları sopaların benzeri olan bir sopayla, sopanın elinden alınması üzerine ise, içerisinde çok sayıda mermi bulunmasına rağmen tabancayla yalnızca yakın mesafeden ve hedef gözetme imkanı olmadan iki kez ateş etmek suretiyle defetmeye çalıştığı**nın anlaşılması karşısında, **S'nin kendisini başka türlü savunmasının imkansız olduğu, saldırının bir sonucu olan ve saldırgana karşı gerçekleştirilen fiilinde meşru müdafaa şartlarının bulunduğu**nun kabulü gerekmektedir.

Bu durumda somut olayda sanığın öldürme suçuna teşebbüs fiilinde meşru müdafaa şartları bulunduğuna ilişkin yerel mahkeme hükmünde herhangi bir isabetsizlik bulunmamakta ise de, CMK'nın 223. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca; "yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması" halinde **beraat kararı** verilmesi gerektiği gözetilmeden, adı geçen sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi yerinde değildir": Yargıtay CGK, **10.12.2013**, E. 2013/1-60, K. 2013/603.

⁵²⁷ Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen.

⁵²⁸ KAUFMANN, Arthur: *Zur Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen*, in: JZ 1954, sh. 653; aynı yazar: *Tatbestand, Rechtfertigungsgründe und Irrtum*, in: JZ 1956, sh. 353, 393; ROXIN, *Offe-*

rinden birinin şartlarının gerçekleşmediği hususundaki bilgi, kasta dahil edilmektedir⁵²⁹. Hukuka uygunluk sebebinin şartlarında yanılğı, suçun unsurlarındaki yanılğı (unsur yanılğısı) ile aynı muameleye tabi tutulmuş olacaktır⁵³⁰.

Bu durum, Türk Ceza Hukuku bakımından rızanın hem salt bir hukuka uygunluk nedeni olmadığının hem de bütünüyle tipikliği kaldıran bir etkisi olmadığının göstergesidir. Nitekim doktrinde de rızanın sadece bir hukuka uygunluk nedeni olarak ele alınması durumunda “suç tiplerinde açıkça yer verilen ‘rızaya aykırılık’ unsurunun ne tür bir anlam ifade ettiği sorusuyla karşılaşılacağı” haklı olarak belirtilmektedir. Bu bağlamda ilgilinin rızası konusunda hukukumuzda da “**tipikliği kaldıran rıza**” ve “**hukuka aykırılığı kaldıran rıza**” şeklinde ikili bir ayrıma gidilmektedir.

Açıklanan rıza fiili hukuka uygun hale getiriyorsa, **hukuka aykırılığı kaldıran rızadan, hukuka uygunluk sebebi olan rızadan** söz edilir. Buna karşılık, açıklanan rıza, fiili suç olmaktan çıkarmakla birlikte, bu rızaya rağmen fiilin hukuka aykırılık özelliğini muhafaza ettiği durumlarda, **tipikliği kaldıran rıza** söz konusudur.

Açıklanan rızanın, bu rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen fiili hukuka uygun hale mi getirdiğini, yoksa hukuka aykırılık vasfını muhafaza etmekle birlikte sadece suç olmaktan mı çıkardığını, suçun kanuni tarifine bakarak belirleme imkânı bulunmamaktadır. Aşağıda örnekleriyle açıklandığı üzere, bu belirlemeyi, **rızanın ilişkin olduğu konuyu** ve ilgili suç tanımı ile **korunan hukuki değeri** dikkate alarak yapmak mümkün olur.

Tipikliği kaldıran rızanın varlığı halinde, bu rıza, sadece işlenen fiilin haksızlık muhtevasını azalmasına sebebiyet verir. Evli bir kişiyle zorla cinsel ilişkide bulunulması, cinsel saldırı suçunu oluşturur. Bu ilişkiye evli kişinin rıza göstermesi, esasen haksızlık oluşturan bu fiili sadece suç olmaktan çıkarır; bu durumda fiil, hukuka aykırılık vasfını muhafaza eder⁵³¹.

ne Tatbestände, sh. 174 vd.; aynı yazar, *Kriminalpolitik*, sh. 25, dn. 56; aynı yazar, *ZStW 76(1964)*, sh. 582, 599; SAMSON, *Systematischer Kommentar, Vorbem. vor § 32*, kn. 9; TOROSLU, *Ceza Hukuku*, sh. 55 vd. Genel bilgi için bkz. HIRSCH, Hans Joachim: *Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen. Der Irrtum über einen Rechtfertigungsgrund*, 1960, sh. 21 vd.

⁵²⁹ Arth. KAUFMANN, *JZ 1954*, sh. 653; aynı yazar, *JZ 1956*, sh. 353, aynı yazar: *Der Irrtum im Strafgesetzentwurf 1962*, in: *ZStW 76(1964)*, sh. 543, 564 vd.; ROXIN, *ZStW 76(1964)*, sh. 582, 599; BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 21, kn. 40.

⁵³⁰ Bkz. ÖZGENÇ, *Suçun Yapısında Kusur*, sh. 88 vd.

⁵³¹ Alman Ceza Kanununda üst soy ve alt soy veya kardeşler arasındaki rızaya dayalı cinsel ilişki suç olarak tanımlanmıştır (§ 173). Bu suç, re’sen soruşturmaya tabidir. Dolayısıyla, bu suçla ilgili soruşturma ve kovuşturma sürecinde beden muayenesi ve vücuttan örnek alma gibi delil elde etme yöntemlerine başvurulabilmektedir.

Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin 26.02.2008 tarihli kararına konu olay, kardeş olan 1976 doğumlu (S) ile 1984 doğumlu (K) arasında gerçekleşen cinsel ilişki eylemlerine iliş-

Failin, işlediği suç bakımından kastından söz edebilmek için, ister tipikliği kaldıran ister hukuka uygunluk sebebi olan rıza olsun, ilgili kişinin rızasının olmadığını bilmesi gerekir. İlgili kişinin rızasının yokluğu konusundaki bilgi, failin kasten hareket ettiğinin kabul edilebilmesi için gereklidir⁵³².

Hukuk düzeni, kişiyi kendisiyle ilgili belli konular üzerinde başkaları tarafından belli tasarruflarda bulunma hususunda rıza göstermeye yetkili kılmaktadır.

Kişinin hukuki yetkisini kullanmak suretiyle açıklamış bulunduğu rızaya dayalı olarak başkaları tarafından gerçekleştirilen davranışlar hukuka aykırı değildir. Belli konularla ilgili olarak belli tasarruflara yönelik hukuken geçerli rızaya dayanılarak gerçekleştirilen davranışlar hukuka uygundur⁵³³.

Rıza açıklamasının bir hukuka uygunluk sebebi oluşturabilmesi için, rızanın ilişkin bulunduğu konu üzerinde ve hukuken tanınan sınırlar kapsamında bir tasarrufta bulunulması gerekir.

Öncelikle, kişinin üzerinde tasarrufta bulunabileceği bir konunun varlığı gereklidir. Örneğin kişi, vücudu üzerinde, sahip bulunduğu malvarlığı üzerinde belli tasarruflarda bulunma yetkisini haizdir; buna karşılık, hayatı⁵³⁴ ve şerefi üzerin-

kindir. (S) ve (K), çeşitli ailevi nedenlerle birbirinden ayrı büyümüş ve ilk defa 2000 yılında (S) yirmi dört ve (K) on altı yaşında iken karşılaşmışlardır. (S) ile (K) arasında gerçekleşen ilişki sonucunda 2001, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında dört çocuk dünyaya gelmiştir. (S) hakkında bu süreçte kovuşturma yapılarak, çeşitli hapis cezalarına hükmolunmuştur. (S), mahkemece verilen mahkûmiyet hükmüne karşı, Alman Ceza Kanunun § 173 hükmünde düzenlenen suçun anayasaya aykırı olduğu ve anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile Federal Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Mahkeme, değerlendirmesinde aile içi cinsel ilişki fiillerinin suç olarak düzenlenmesi ile ilgili üç hususa vurgu yapmıştır. Bunlardan ilki aile düzeninin korunması; ikincisi kardeşler arasında gerçekleşen bir cinsel ilişkide taraflardan en azından birisinin cinsel özgürlüğünün korunması ve sonuncusu, kardeşler arası cinsel ilişkiden meydana gelecek çocukların genetik olarak engelli olmaya yatkın olmalarıdır. Mahkeme bu gerekçeler ile belirli derecede hısımlar arasında gerçekleşen cinsel ilişkinin ceza yaptırımına bağlanmasının anayasaya aykırı olmadığına hükmetmiştir. Mahkemenin kararı doktrinde ciddi şekilde eleştirilmiş, mahkeme üyelerinden HASSEMER de karara muhalif kalarak bir karşı oy yazısı kaleme almıştır.

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, 2 BvR 392/07. Karar metni için bkz. <https://www.hrr-straftrecht.de/hrr/bverfg/07/2-bvr-392-07-1.php> (Erişim tarihi: 17.7.2024)

⁵³² İster tipikliği kaldıran ister hukuka uygunluk sebebi olan rıza olsun, ilgili kişinin rızasına istinaden gerçekleştirilen fiil dolayısıyla, fail hakkında beraat hükmü verilecektir. Ancak, verilecek olan beraat hükmünün kanuni dayanakları farklılık arz edecektir. Tipikliği kaldıran rızanın varlığı halinde, fail hakkında verilecek beraat hükmünün dayanağını CMK, m. 223, f. 2, bent a oluşturmaktadır. Buna karşılık, hukuka uygunluk sebebi olan rızanın varlığı halinde fail hakkında verilecek beraat hükmünün dayanağını ise, CMK, m. 223, f. 2, bent d oluşturmaktadır.

⁵³³ Bkz. EKİCİ ŞAHİN, Meral: *Ceza Hukukunda Rıza*, İstanbul, Ocak 2012, sh. 50 vd.

⁵³⁴ Kişinin hayatiyeti üzerinde tasarruf yetkisinin varlığı hukuken kabul edilemez. Yani, kişinin öldürülmesi yönündeki rızanın hukuki bir değeri yoktur.

Bu mülahazaya binaen, “*Hasta Hakları Yönetmeliği*”nde 13. maddesinde “**Ötenazi yasağı**” başlığı ile şu hükme yer verilmiştir:

«Ötenazi yasaktır.

Tıbbî gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez.»

Kişinin kendi hayatı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisi bulunmamaktadır (SO-YASLAN, Özel Hükümler, 2. bası, sh. 75; CENTEL, Türk Ceza Hukuku, sh. 235).

İnsan, hayatını sürdürme konusunda bir sevkî tabîî ile karşı karşıyadır. Ancak, aklî melekelerin bozukluğu nedeniyle veya müptela olduğu hastalıktan kaynaklanan acı ve ızdırabın etkisiyle kişide hayatını sona erdirmeye yönelik bir eğilim ortaya çıkabilir ve bunu bir irade açıklamasıyla ortaya koyabilir (ÖNDER, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler, sh. 78). Belirtmek gerekir ki, kişinin bu şartlar altında hayatını sona erdirmeye yönündeki iradesinin hukukî geçerliliği söz konusu değildir. Başka bir deyişle, belirtilen durumlarda hukukîen muteber bir iradeden söz etmek mümkün değildir. Bu itibarla, bir insanın yaşayıp yaşamama yönünde “*kendi akıbetini serbestçe belirleme hakkı*”ndan veya “*intihar edebilme hakkı*”ndan (DÖNMEZER, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, no. 22, 56) söz edilemez. Nitekim, Alman Federal Yüksek Mahkemesi de bir kararında intihar olgusunun **ahlaka aykırı** olduğu yönünde karar vermiştir: BGH 6, 151-153 (Nakleden HAKERİ, Doçentlik Tezi, sh. 191).

Günümüz ceza kanunlarının bazılarında “*talep üzerine öldürme*” suçu tanımına yer verilmektedir (meselâ, Alman CK., §216, Avusturya CK., §189/a). Öldürülmeyi talep eden kişinin iradesi, öldürme fiili açısından bir hukuka uygunluk sebebi oluşturmamaktadır. Bu gibi durumlarda iki hususun göz önünde bulundurulması gerekir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, öldürülmeyi talep eden kişinin içinde bulunduğu psikolojik durum, çektiği acı ve ızdırıp, bu yönde bir açıklamada bulunmasında etkili olmaktadır (EREM, Adam Öldürmek Cürümleri, sh. 7/8). Keza, çektiği acı ve ızdırabın etkisiyle öldürülmesini talep eden kişinin bu yöndeki yaklaşımları ve çektiği acı karşısında bu kişiyi öldüren yakınının veya sağlık görevlisinin tam bir irade serbestisiyle hareket ettiği de söylenemez. Bu itibarla, talep üzerine öldürme fiillerinde sorunun kusurlulukla yani irade serbestisiyle bağlantılı olarak bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Nitekim yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısının “*Acıyı dindirme saiki*” başlıklı 140. maddesinde yeni bir suç tanımına yer verilmiştir:

«İyileşmesi olanağı bulunmayan ve ileri derecede ızdırıp verici bir hastalığa tutulmuş olan bir kimsenin, bilincinin ve hareketlerinin serbestliğine tam olarak sahip iken yaptığı ısrarlı talepleri üzerine ve sadece hastanın ızdıraplarına son vermek maksadıyla öldürme fiilini işlediği sabit olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.»

Belirtmek gerekir ki, doktrinde bazı yazarlar tarafından 765 s. mülga TCK’nın sisteminde bu gibi durumlarda “*taammüden adam öldürme*”nin (m. 450, b. 4) varlığını kabul etmek gerektiği fikri ileri sürülmüştür (DÖNMEZER, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, no. 23; ERMAN/ÖZEK: Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, sh. 16).

Bazı durumda kişiler, belli bir uygulamayı protesto zımında yemek yememek veya su içmemek yönünde tercihte bulunmaktadır. Protesto amaçlı bu “*oruç*” eylemleriyle kişiler sakat kalmayı ve hatta ölümü de göze almaktadırlar. Bu nedenle, söz konusu eylemlere “*ölüm orucu*” eylemleri de denmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir kişinin hayatı üzerinde tasarruf yetkisinin kabul edilmemesi dolayısıyla, bu tür protesto eylemlerinin bir “hak icrası” olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Ancak, iradesi bu yönde oluşmuş olan kişilerin zorla beslenme ihtiyacının karşılanması doğru ve hatta mümkün değildir.

Bu nedenle, protesto amaçlı “*ölüm orucu*” eylemlerinde, eyleme katılan kişilerin bu yöndeki tercihlerinin doğru olmadığı yönünde bilgilendirilmesi ve bu eylemlerinden vazgeçmeleri için ikna edilmeye çalışılması gerekir. Buna rağmen, gerekli bilgilendirme ve ikna gayretlerinin sonuç vermemesi durumunda, gerekli beslenmeyi ihmal ederek sonuçta ölen kişinin bu ölümden herhangi birini sorumlu tutmak mümkün olmamak gerekir.

Buna karşılık, doktrinde kabul gören görüşe göre; protesto amaçlı “*ölüm orucu*” eylemlerine müdahale edilmemesi, kamu görevlileri (cezaevi hekimi ve yöneticileri) açısından “*görevi*

de tasarrufta bulunma yetkisine sahip değildir. Rıza, kişinin üzerinde tasarrufta bulunabileceği bir konu ile ilgili olmalıdır. Bu nedenle, kişi kendisine hakaret edilmesine rıza gösterse dahi, bu rıza, hakaret fiilini hukuka uygun hale getirmez.

Rızanın, fiil işlenmeden önce ve en geç fiilin icrası sırasında açıklanması gerekir. Fiilin icrası tamamlandıktan sonra açıklanan rıza, yani fiile bilahare **muvafakat** edilmesi, fiilin haksızlık ve hatta suç oluşturmamasını önlemez. Fiilin icrasından sonra açıklanan rıza, yani bilahare fiile muvafakat edilmesi, bu fiil nedeniyle örneğin özel hukuk hükümlerine göre tazminat sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır. Örneğin hırsızlık suçunda malı çalınan kişi bilahare malının alınmasına çeşitli sebeplerle muvafakat edebilir, malını çalan kişiye hakkını “helâl” edebilir. Bu durum, işlenen fiili hukuka uygun hale getirmez ve hatta, hırsızlık suçundan dolayı ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu durum, sadece hırsızlık suçundan dolayı verilecek olan temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilir.

Rıza, kişinin üzerinde tasarrufta bulunabileceği bir konuya ilişkin olmakla birlikte; hukuk düzeni, konu üzerindeki tasarruf biçimi bakımından da rıza açıklanmasına sınırlamalar getirmektedir. Örneğin, kişi sahibi bulunduğu malvarlığı üzerinde başkalarının tasarrufta bulunmasına rıza gösterebilir. Ancak, örneğin bir yerleşim bölgesindeki binanın yakılmasına yönelik olarak açıklanan rızaya hukuki geçerlilik tanınmamıştır (TCK, m. 170, 171).

Kişinin vücudu üzerinde ancak belirli nitelikteki ve belirli amaçlara yönelik tasarruflarda bulunulmasına yönelik olarak açıkladığı rızaya hukuken geçerlilik tanınmaktadır. Örneğin kişi berberde saçlarının kestirilmesine, kulağında küpe deliği açılmasına rıza gösterebilir; ancak, kulağının kesilmesine rıza gösterdiğinde, bu rızaya hukuki geçerlilik tanınmamıştır.

Kişinin, rızanın ilişkin olduğu konu üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine sahip olması gerekir. Keza, kişinin, bir konu üzerinde başkasının muayyen bir tasarrufta bulunabilmesine yönelik olarak rıza açıklama yeteneğine sahip olması gerekir. Örneğin, çocuklar üzerinde bilimsel deneyin suç oluşturmaması için, Kanunun “*İnsan üzerinde deney*” başlıklı 90. maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen diğer koşullardan başka, “*rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin alınması*” gerekmektedir (bent b).

ihmal suçu”nu oluşturur (SOYASLAN, Genel Hükümler, sh. 279, 280; FEYZİOĞLU, Metin: *Açlık Grevi*, Ankara ÜHFD, 1993, c. 43, sayı 1-4, sh. 157 vd. [167]; EREM, Ceza Hukukunda İntihar, Yargıtay Dergisi, c. XVI, Ekim 1990, sayı 4, sh. 49 vd. sh. [496]; HAKERİ, sh. 170, dn. 412). İNCEOĞLU, Sibel: *Ölme Hakkı*, İstanbul, 1999; ARTUK, M. Emin: “*Ötanezi*”, Yargıtay Dergisi, cilt XVIII, Temmuz 1992, sayı 3, sh. 300 vd.; ÇAĞLAYAN, Muhtar: *Ötanezi ve İntihar*, AD, LVII, 1, 1966, sh. 5).

Bazı hallerde, rıza açıklamasına hukuki değer izafesi, usule ilişkin belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı kılınabilir. Bir tıbbî müdahaleye ilişkin olarak açıklanan rızanın hukuki geçerliliğinin, *aydınlatma yükümlülüğünün* yerine getirilmesine bağlı kılınması, bu bakımdan önemli bir örnek oluşturmaktadır.

Keza, yetişkinler üzerinde bilimsel deneyin suç oluşturmaması için, Kanunun 90. maddesinin ikinci fıkrasında aranan diğer koşulların yanı sıra; “*deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması*” gerekmektedir (bent g).

Yine, aynı maddenin dördüncü fıkrasında tedavi amaçlı denemenin suç oluşturmaması için aranan koşullar belirlenmiştir:

*“Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbî müdahale yöntemlerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. **Açıklanan rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı olması** ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması gerekir.”*

Kanunun “*Organ veya doku ticareti*” başlıklı 91. maddesinde “*hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ (veya doku) alan kimse, ... cezalandırılır.*” hükmüne yer verilmiştir (f. 1). Buna göre, hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, yaşayan kişiden organ veya doku alınması, suç oluşturmaktadır. Fiili suç olmaktan çıkaran rızanın hukuken geçerli rıza olması gerekir. Açıklanan rızanın hangi koşullarda hukuken geçerli olacağı, 29.5.1979 tarihli ve 2238 sayılı *Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun*da düzenlenmiştir⁵³⁵.

Kanunun “*Çocuk düşürtme*” başlıklı 99. maddesinde “*rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, ... cezalandırılır.*” hükmüne yer verilmiştir (f. 1). Burada söz konusu olan rıza, 24.5.1983 tarihli ve 2827 sayılı *Nüfus Plânlaması Hakkında Kanun*da yer alan hükümlere göre geçerli olan bir rızadır⁵³⁶. Ancak, karşıt anlamından (mefhumu muhalifinden) hareketle, bu

⁵³⁵ Bu konuda bkz: BAYRAKTAR, Köksal: *Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılması ve Nakli Hakkında Kanun’a İlişkin Düşünceler*, in: Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, İstanbul 1979, sh.15 vd.; TOROSLU, Nevzat: *Organ Aktarma ve Ceza Sorumluluk*, Ankara ÜHFD, cilt XXXV, yıl 1978, sayı 1-4, Ankara 1981, sh. 91 vd..

⁵³⁶ 24.5.1983 tarih ve 2827 sayılı *Nüfus Planlaması Hakkında Kanun*, gebeliğin sona erdirilmesini ve rahim tahliyesini ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Söz konusu Kanunun 6. maddesinde **gebeliğin sona erdirilmesi hususunda kimlerin ve hangi şartlarda rıza gösterebileceği** belirlenmiştir. Buna göre; rahim tahliyesine ilişkin “*müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile velinin iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasiinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine*

düzenlemeden, rızaya dayalı olarak çocuk düşürtmenin hukuka aykırı ve suç olmadığı sonucu çıkarılamaz.

Belirtmek gerekir ki, **bazı durumlarda rıza açıklaması**, bu rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen **fiili hukuka uygun hale getirmez**; aksine, kişi bu rızaya dayalı olarak gerçekleştirdiği fiilden dolayı olayda bir zorunluluk halinin varlığı nedeniyle kusurlu addedilmez ve sorumlu tutulmaz.

Örneğin, “kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için, gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.” (m. 99, f. 6).

Aslında bu durumda, gebe bırakılan kadın açısından bir zorunluluk hali söz konusudur. Ancak, bu zorunluluk halinin varlığına rağmen, gebeliğin sona erdirilmesi yine de kadının rızasına bağlı kılınmıştır. Fakat, belirtmek gerekir ki, rızanın varlığına rağmen, bu rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen gebeliği sona erdirmeye yönelik fiil hukuka uygun değildir. Bu gibi durumlarda, kadının içinde bulunduğu zorunluluk halinden, açıkladığı rızaya dayalı olarak gebeliği sona erdiren hekimin de yararlanması söz konusudur⁵³⁷.

Aynı şekilde, tıbbî zorunluluk bulunmadığı takdirde, “rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, ... cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürülmesine rıza gösteren kadın” da cezalandırılır (m. 99, f. 2).

Bu hükmün karşıt anlamından çıkan sonuca göre, gebelik süresi on haftayı geçmesine rağmen, **tıbbî zorunluluk** nedeniyle ve ayrıca, kadının rızasına dayalı olarak gebelik sona erdirilebilir. Demek ki on haftayı aşkın gebeliklerde gebeliğin sona erdirilmesi için önce bir tıbbî zorunluluğun bulunması gerekir. Kanun, bu

bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz.” (f. 1)

Keza, gebe kadın evli ise, “**rahim tahliyesi için eşin de rızası gerekir.**” (m. 6. f. 2)

⁵³⁷ TCK’nın 99. maddesinin altıncı fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için, kadının mağduru olduğu bir suç sebebiyle gebe kalmış olması gerekir. Bu hüküm, doktrinde bazı yazarların ileri sürdüğünün aksine, kadının salt beyanına istinaden kürtajın gerçekleştirilmesine imkan vermez. Ortada bir suç olgusu söz konusu olduğu için, bu suç sebebiyle mutlaka soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olması ve kürtajın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının veya davanın görüldüğü mahkemenin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu itibarla, henüz soruşturma veya kovuşturmayla konu edilmemiş bir suçtan bahisle gebeliğin sona erdirilmesine yönelik girişimde bulunulması halinde, TCK’nın 99. maddesinin altıncı fıkrası hükmüne istinaden ceza sorumluluğundan sarfınazar edilemez (Bu hususa ilişkin tutarlı olmayan açıklamalar için bkz. ÜNVER, Yener: *Hekim ve Hasta Haklarının Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Konumlandırılması*, in: *Ceza Hukuku Dergisi (CHD)*, yıl 2, sayı 1, Nisan 2007, sh. 212 vd.; aynı yazar: *Türkiye’de Ceza Hukuku Alanında Yapılan Yakın Tarihli Düzenlemelerde Tıp Hukukuna İlişkin Birkaç Sorun*, in: *Uluslararası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyum Kitabı*, İstanbul, 2005, sh. 105 vd.).

tıbbî zorunluluk kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda bir açıklık içermemektedir. Bunun, Türk Ceza Kanunu bakımından bir eksiklik olduğu düşünülmemelidir. Ancak, bu hususta şunu ifade etmek gerekir ki; bu tıbbî zorunluluğun varlığının hangi hallerde söz konusu olabileceği, tıbbî deontoloji kuralları ile ananın ve ceninin sağlığı bakımından ayrı ayrı olarak belirlenmelidir.

Bir tıbbî zorunluluk nedeniyle ve kadının rızasına dayalı olarak gebeliğin sona erdirilmesi halinde de kusurluluğu ortadan kaldıran bir zorunluluk halinin varlığını kabul etmek gerekir. Başka bir deyişle, bu gibi durumlarda kadının salt rızasının varlığı, fiili hukuka uygun hale getirmemektedir⁵³⁸.

Aynı değerlendirmenin, tıbbî zorunluluk bulunmadığı halde, on hafta veya on haftadan kısa süreli gebeliklerin sona erdirilmesiyle ilgili olarak da yapılabileceğini düşünmekteyiz. Başka bir deyişle, kanımızca, on hafta veya on haftadan kısa süreli gebeliklerin sona erdirilmesi bakımından **sosyal endikasyonun** varlığını aramak gerekir. Ancak, bu gibi durumlarda, bir hukuka uygunluk sebebi değil, **kusurluluğu ortadan kaldıran zorunluluk halinin** varlığını kabul etmek gerekir⁵³⁹.

Bazı suç tanımları bağlamında rızanın varlığına bir hukuki değer izafe edilmemiştir. Bu durumlarda, rızanın varlığı bir hukuka uygunluk nedeni oluşturmamaktadır.

Örnek 1. Kanunun “İnsan ticareti” başlıklı 80. maddesinde tanımlanan suç oluşturana fiiller bakımından açıklanan rızaya hukuki geçerlilik tanınmamıştır:

“(1) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla, tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçırarak, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.” (Ayrıca bkz. m. 117, f. 2 ve gerekçesi).

Örnek 2. “Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi”, suç oluşturmaktadır (m. 101, f. 2).

Örnek 3. “Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte (maruz kaldığı) fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan ço-

⁵³⁸ Bu mülahazayadır ki, Almanya’da 1995 yılında yapılan bir kanuni düzenlemeyle hekimin rahim tahliyesi yapmakla yükümlü kılınmayacağı hüküm altına alınmıştır (Schwangerschaftskonfliktgesetz, Paragraf [§]12, f. 1). Hatta söz konusu Kanunun hazırlanmasında, Alman hukukunda kürtajın bir hak olarak telakki edilmemesi, belirleyici olmuştur.

⁵³⁹ Bu bakımdan, kadının “çocuğu düşürmek hakkı”ndan söz eden Ünver’in görüşü (ÜNVER, CHD, Nisan 2007, sh. 220) hukuki dayanaktan yoksundur.

cuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından, rızanın varlığı ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Başka bir deyişle, kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından bu çocuğun rıza açıklamasında bulunması, fiili suç olmaktan çıkarmayacak ve kişinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Bu bakımdan, onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte maruz kaldığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan kişilere karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, cinsel istismar olarak kabul edilmiştir.” (m. 103 gerekçesi⁵⁴⁰)⁵⁴¹.

⁵⁴⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 510 vd.

⁵⁴¹ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.2.2015 tarihli ve E. 2014/14-307, K. 2015/8 sayılı Kararında **rıza** ile ilgili olarak yer verilen şu değerlendirmeler, **sorunludur**:

“Medeni Kanunun 13. maddesinde, yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkesin ayırt etme gücüne sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı Kanunun 16. maddesinde, ayırt etme gücüne sahip küçüklerin kanuni temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremeyecekleri belirtilmiş, ancak karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rızanın gerekli olmadığı hükme bağlanmıştır. **Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar kanunda tek tek sayılmamakla birlikte genel olarak öğretide, kişinin sadece kendisinin kullanabileceği, başkasına devredilemeyen ve miras yoluyla geçmeyen haklar** olarak açıklanmaktadır. Bu tür haklar insanın kişiliğini yakından ilgilendirdiğinden, bunların kullanılmasına karar verme yetkisi başkasına bırakılmamıştır. Örneğin; evlenme, nişanlanma, nişanı bozma, evlat edinilmeye razı olma gibi...

Diğer taraftan, 15.04.1942 gün ve 14-9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve Ceza Genel Kurulunun 15.02.1972 gün ve 43-50 ile 02.03.2004 gün ve 44-58 sayılı kararlarında; ayırt etme gücüne sahip (sezgin) küçüklerin doğrudan doğruya kişiliklerine karşı işlenmiş bulunan suçlardan dolayı dava ve şikâyet hakkına sahip oldukları belirtilmektedir.

Ceza Genel Kurulunun 10.06.2014 gün ve 551-311, 12.11.2013 gün ve 511-449 ile 11.03.2008 gün ve 253-52 sayılı kararlarında da vurgulandığı üzere; 5237 sayılı TCK’nın 6/1-a maddesinde, “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanan çocuk kavramının, kanun koyucu tarafından cinsel dokunulmazlığa karşı suçların düzenlendiği bölümde, “onbeş yaşını bitirmiş”, “onbeş yaşını tamamlamamış” şeklinde iki ayrı dönem olarak ele alındığı görülmektedir. Buna göre bu bölümde “onbeş yaşını tamamlamamış” çocuklar ile “onbeş yaşını bitirmiş olup da onsekiz yaşını tamamlamamış” çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar farklı kategoride mütalaa edilmiştir. TCK’nın 103/1-a maddesinde, “onbeş yaşını tamamlamamış” olan çocuklara karşı her türlü cinsel davranış cinsel istismar olarak tanımlanmışken, aynı maddenin (b) bendinde ise; diğer çocuklar ifadesiyle “onbeş yaşını bitirmiş olup da onsekiz yaşını tamamlamamış” çocuklar kastedilerek bunlara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışların cinsel istismar suçunu oluşturabileceği kabul edilmiştir. Böylece kanun koyucu bu maddede “**onbeş yaşını bitirmiş olup da onsekiz yaşını tamamlamamış**” olan çocuklara karşı rızalarıyla işlenen cinsel davranışları cinsel istismar suçu kapsamına almamış ve bu kategorideki **çocukların rızalarına önem vermişken**, “onbeş yaşını tamamlamamış” çocuklara karşı yapılan her türlü cinsel davranış rızaları olsa bile çocukların cinsel istismarı suçu kapsamına almıştır. Aynı kanunun 104. maddesinde de; cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunmayı şikâyete bağlı bir suç olarak düzenlemiştir.

Bu düzenlemeden hareketle çocuklara karşı işlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun da iki kategoride ele alınması gerekmektedir:

Birinci kategoride yer alan “**onbeş yaşını tamamlamamış**” çocukların kendi iradeleriyle **serbestçe hareket etme hakkı**, niteliği itibarıyla üzerinde mutlak surette tasarruf edebilecekleri

bir hak olmadığından, bu haklarının ihlaline yönelik olarak gerçekleştirilen eylemlerle ilgili gösterdikleri rıza, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemeyecektir.

Buna karşın ikinci kategoride yer alan “onbeş yaşını bitirmiş olup da onsekiz yaşını tamamlamamış” çocuklara karşı işlenen suçlarda ise, mümeyyiz olmaları halinde rızaları hukuka uygunluk nedeni olabilecektir.

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 30.09.2014 gün ve 389-413 sayılı kararında da aynı sonuca ulaşılmıştır.

Sanığın 15 yaşından küçük mağdureyi evlenmek amacıyla rızasıyla kaçırıp yakın başka bir ildeki akrabalarının evine götürerek orada bir müddet alıkoyduğu somut olayda, mağdurenin rızası hukukî olarak mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olmadığından hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemeyecektir. Dolayısıyla 15 yaşından küçük mağdurenin rızasıyla bile gerçekleşmiş olsa bu eylem TCK'nın 109/1, 109/3-f, 109/5. maddelerinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmaktadır.” (Ayrıca bkz. CGK, 16.6.2015, E. 2014/14-465, K. 2015/235).

Söz konusu kararda yer alan, çocuğun, kendi vücudu üzerinde bir başkasının cinsel tasarrufta bulunmasına yönelik rıza açıklamasının, yaşına göre oluşan suçun nitelendirilmesinde bir farklılık meydana getirdiği hususundaki açıklamalar doğrudur.

Ancak, çocuğun cinsel istismarı suçu ile TCK, m 104, f. 1’de tanımlanan suç arasındaki rızaya dayalı bu farklılığın, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna taşınmasına yönelik değerlendirmeler doğru olmamıştır.

Söz konusu kararda, onbeş yaşını henüz doldurmamış olan bir çocuğun bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hususunda açıklamış bulunduğu rızayı mutlak anlamda geçersiz sayan bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu değerlendirmeye göre, henüz onbeş yaşını tamamlamamış olan çocuğu kendi rızasıyla ve örneğin ders çalışmak gibi meşru bir amaçla evine kabul eden kişinin fiili de kişiyi hürriyetinden yoksun kılması suçunu oluşturacaktır.

Buna karşılık, “onbeş yaşını bitirmiş olup da onsekiz yaşını tamamlamamış” çocuğun, mümeyyiz olması halinde, bir yere gitmek veya bir yerde kalmak konusunda açıkladığı rızanın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından bir hukuka uygunluk nedeni oluşturduğu kabul edilmiştir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından sorun, çocuğun bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hususunda açıklamış bulunduğu rızanın amacına göre bir değerlendirmeye tabi tutularak çözümlenmesi gerekir. Hangi yaşta olursa olsun, çocuğun bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hususunda açıklamış bulunduğu rıza, şayet meşru bir amaca yönelik ise, bir hukuka uygunluk nedeni oluşturacaktır. Bu itibarla, okula gitmek isteyen bir çocuğun dolmuşa, taksiye binerek seyahat etmesi halinde, ortaya koyduğu bu irade, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından bir hukuka uygunluk nedeni oluşturacaktır. Keza, okuldan dönen çocuğun evde kimsenin bulunmaması ve kapının kilitli olması sebebiyle komşu eve giderek bir süre kalması yönünde ortaya koyduğu irade, çocuğu eve kabul eden komşunun fiilini hukuka uygun hale getirecektir.

Ancak, cinsel amaçla çocuğun bir yere götürülmesi veya bir yerde alıkonulması halinde, çocuğun açıklamış bulunduğu rıza, fiili hukuka uygun hale getirmeyecektir. Çocuk onbeş yaşını tamamlamış olsa bile, açıklamış bulunduğu rıza, cinsel amaçla bir yere götürülmesi veya bir yerde tutulması fiili bakımından bir hukuka uygun nedeni oluşturmayacaktır.

Dikkat edilmelidir ki, rızayı bir hukuka uygunluk sebebi kılan, ilişkin olduğu konu ve amaçtır. Başka bir ifadeyle, ilişkin olduğu konu ve amaç birlikte dikkate alınarak rıza bir hukuka uygunluk sebebi oluşturabilir.

Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarının icrası sırasında kişi belli bir süre bir yere gitmekten alıkonulmakta, hürriyeti kısıtlanmaktadır. Suçun icrası sırasındaki bu hürriyetten yoksun kılma, söz konusu suçların mündemiç olduğu bir durum olduğu için, bu bağlamda ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı cezalandırma yoluna gidilemez.

TCK'nın 102 ve 103. maddelerinde tanımlanan cinsel suçlardan birinin işlenmesi amacıyla kişinin hürriyetinden yoksun kılınması durumunda, cinsel suçun icrasına henüz başlanmamış olsa bile, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hali (TCK, m. 109, f. 5) oluşacaktır. Bu itibarla Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararında izah edilen gerekçeye iştirak etmemekle birlikte, varılan sonucu doğru bulmaktayız.

Cinsel suçlardan birinin işlenmesi amacıyla hürriyetinden yoksun kılınan, bir yere götürülen veya bir yerde alıkonulan kişi üzerinde ayrıca cinsel suçun işlenmesi halinde, gerçek içtima hükümlerine göre, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun yanı sıra, cinsel saldırı (TCK, m. 102) veya çocuğun cinsel istismarı (TCK, m. 103) suçlarından dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir. Aynı yönde değerlendirmeler için bkz. CGK, **12.5.2015**, E. 2013/14-550, K. 2015/158; CGK, **30.6.2015**, E. 2014/14-810, K. 2015/268.

Bu bağlamda TCK'nın 234. maddesinin son fıkrasında tanımlanan suçu da göz önünde bulundurmamak gerekir.

Kanunun söz konusu hükmüne göre,

“Kanuni temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Söz konusu suç bağlamında evi terk eden çocuğu yanında tutan kişinin gayrimeşru bir amacının olması gerekmemektedir. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, aranan şartlar şunlardır:

a) Kanuni temsilcisinin, veli veya vasisinin bilgisi veya rızası olmaksızın çocuğun evi terk etmesi gerekir.

Evi terk eden çocuğun yaşının veya cinsiyetinin bir önemi bulunmamaktadır. Madde metninde alehtlak “çocuk” ibaresi kullanılmıştır. Bu itibarla, suçun konusunun 18 yaşını tamamlamamış olan bir kişi olması gerekir. Ancak, bu kişinin velayet ve vesayet altında olan bir çocuk olması gerekir. Başka bir ifadeyle, henüz 18 yaşını tamamlamamış olmakla birlikte, “kazâî rüşd”le, mahkeme kararıyla reşit kılınan kişi, bu suçun konusunu oluşturamaz.

b) Bu terkin gayrimeşru bir amaca mebni olmaması gerekir.

Bu terk, kanuni temsilciye izafe edilen herhangi bir hukuka aykırı fiile dayanmayabilir. Hatta bu terk, kanuni temsilcinin örneğin kötü muamelesinin dayanılmaz olması sebebiyle de yapılmış olabilir.

Keza, örneğin işlediği suç sebebiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasından kurtulmak için çocuğu yanında tutan, barındıran kişinin fiili, TCK, m. 234, f. 3'te tanımlanan suçunu değil, suçluyu kayırma (TCK, m. 283) suçunu oluşturur.

c) Bir başkasının, evi terk eden çocuğu yanında tutması, barındırması gerekir.

ç) Kanuni temsilcisinin bilgisinin veya rızasının olmamasına rağmen çocuğu yanında tutan, barındıran kişinin, ailesine, veli veya vasisine ya da yetkili makamlara (kolluğa) durumu haber vermemesi gerekir.

d) Çocuğu yanında tutan, barındıran kişinin, veli veya vasisinin bilgisi veya rızası olmaksızın çocuğun evi terk ettiğini bilmesi gerekir.

Bu yönü itibarıyla söz konusu suç, ancak kasten işlenebilir. Kanaatimizce bu kastın **doğrudan kast** olması gerekir.

e) Çocuğu yanında tutan, barındıran kişinin gayrimeşru herhangi bir amacının olmaması gerekir: 14.CD, **25.4.2013**, E. 2012/8966, K. 2013/4982.

Bu itibarla, evi terk eden çocuğu yanında tutan kişinin cinsel amaçla hareket etmesi halinde, TCK, m. 234, f. 3'te tanımlanan suçtan dolayı değil, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halinden dolayı TCK, m. 109, f. 1, f. 3 [bent f] ve f. 5 hükümlerine istinaden cezaya hükmedilecektir.

İşaret etmek gerekir ki, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun oluştuğu durumlarda, TCK, m. 234, f. 3'de tanımlanan suçunun uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır.

Bu durum karşısında, çocuğun bir yere gitmek veya bir yerde kalmak yönünde açıkladığı rıza ile ilgili olarak **iki ihtimale** göre değerlendirme yapmak gerekir.

Birinci ihtimal: Yaşı ne olursa olsun, cinsel suçlardan birini işlemek amacıyla, çocuğun cebir, tehdit veya hile kullanılarak bir yerden alınıp başka bir yere götürülmesi veya bir yerde alıkonulması halinde, TCK'nın 109. maddesinin beşinci fıkrasında tanımlanan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hali oluşacaktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **16.6.2015** tarihli ve E. 2014/14-465, K. 2015/235 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, 20.11.1996 doğumlu olan ve olay tarihi itibarıyla henüz on-dört yaşını tamamlamamış olan Dilek, bir süre duygusal arkadaşlık yaptığı Tayfun ile anlaşarak, 2.8.2010 tarihinden itibaren Tayfun'un bir yakınının evinde üç gün süreyle birlikte olurlar. 5.8.2010 tarihinde ise Tayfun Dilek'i kendiliğinden serbest bırakır.

Ceza Genel Kurulu, söz konusu olayda, mağdure Dilek'e karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun oluştuğunu kabul etmiştir:

*“Sanığın bir süredir duygusal arkadaşlık yaptığı 15 yaşından küçük mağdureyi kendi rızası dahilinde bir yakınının evinde üç gün süreyle alıkoymak biçimindeki eyleminde, mağdurenin rızası hukukun üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olmadığından hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemeyecektir. Dolayısıyla 15 yaşından küçük mağdurenin rızasıyla bile gerçekleşmiş olsa bu eylem TCK'nın 109/1, 109/3-f, 109/5. maddelerinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmaktadır”. (Ayrıca bkz. CGK, **30.6.2015**, E. 2014/14-678, K. 2015/267; CGK, **30.6.2015**, E. 2014/14-368, K. 2015/266; CGK, **17.2.2015** tarihli ve E. 2014/14-307, K. 2015/8; CGK, **30.9.2014**, E. 2014/14-389, K. 2014/413).*

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun **20.09.2016** tarihli ve E. 2014/14-601, K. 2016/314 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; olay tarihi itibarıyla yaşı 14 yıl 10 ay 22 gün olan M, ailesinin bilgisi ve rızası dışında, aralarında duygusal bağ olan S ile birlikte kaçır ve altı gün süreyle S'nin ailesi yanında kalır. Ancak, bu süre zarfında M ile S arasında cinsel ilişki gerçekleşmez.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu olayda da, aşağıdaki gerekçe ile, S'nin fiilinin, TCK, m. 109'da tanımlanan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğu yönünde içtihatla bulunmuştur:

“Madde gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, (TCK, m. 234, f. 3'te tanımlanan) suçla korunan hukuki değer, veli ya da vasinin çocuk üzerinde sahip olduğu velayet veya vesayet hakkıdır. Kanuni temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evini terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeden, rızasıyla da olsa yanında tutan kişi şikâyet üzerine cezalandırılacaktır. Çocuğun, kanuni temsilcisinin bilgisi ve rızası olmadan fakat kendi isteği ve arzusuyla evi terk edip rızasıyla failin yanına gitmesi veya onun yanında rızasıyla kalması bu suçun oluşması bakımından önşart niteliğindedir. Kanuni temsilcinin rızasının bulunması suçun oluşmasına engel olacaktır. Fail, çocuğun ailesine veya yetkililere bildirme yükümlülüğünü somut olaya göre belirlenebilecek makul bir süre içerisinde yerine getirdiği takdirde, çocuğu yanında tutsa bile eylemi suç teşkil etmeyecektir.

...

Kişilerin isteklerini ve serbest iradeleriyle hareket edebilme özgürlüğünü koruyan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu (TCK, m. 109), bir kimsenin bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakılması hareketlerinden herhangi birisinin veya her ikisinin birlikte gerçekleştirilmesiyle oluşan seçimlik hareketli bir suçtur. Suç konusu eylemle, kişinin kendi arzusuna göre bulunduğu yerde kalma ya da oradan ayrılma, yer değiştirme ve istediği yere gidebilme yani serbestçe hareket etme veya kendi iradesiyle hareket etmeme hakları ihlâl edilmektedir.

5237 sayılı TCK'nın esas aldığı ve suçun bir haksızlık olarak adlandırıldığı suç teorisinde suçun unsurları; maddi unsurlar, manevi unsurlar ve hukuka aykırılık unsuru olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır.

Uyuşmazlıkla yakından ilgili olan hukuka aykırılık, suçu oluşturan haksızlığın niteliği olup hukuka aykırılık ile kastedilen husus, fiilin hukuk sistemiyle çatışması ve hukuk sistemine aykırı olmasıdır. 5237 sayılı Kanunda bazı suç tanımlarında “hukuka aykırı olarak”, “hukuka aykırı başka bir davranışla”, “hukuka aykırı diğer davranışlarla”, “hukuka aykırı yolla”, “hukuka aykırı yollarla” gibi ifadelerle yer verilmiştir. Suçun unsurlarından birisi olması sebebiyle “hukuka aykırılık” kavramına madde metninde ayrıca yer verilmesiyle, failin olayda haksızlık bilinciyle hareket etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

...

İlgilinin rızası TCK'nın 26/2. maddesinde, “kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmmez” şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, suçla korunan hukuki yararın sahibinin ihlale rıza göstermesi durumunda, bu rıza failin ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldırabilmesi için rızanın, üzerinde serbestçe tasarruf edilebilir bir hukuki menfaate ilişkin olması, kişinin rıza açıklamasına ehil olması ve tasarrufun kanuna, adaba ve genel ahlaka aykırı şekilde yapılmamış olması gerekir. Bu noktada bir hakkın üzerinde serbestçe tasarruf edilip edilemeyeceği hukuk düzenine hakim genel ilkelere göre belirlenecektir.

Kişinin rıza ehliyetinin varlığından söz edebilmek için o kişinin mutlaka reşit olması gerekmez. Ancak Kanunun özel olarak mağdurun yaşı konusunda belirlemeye gittiği durumlarda, mağdurun rızası failin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Örneğin kişiler cinsel hakları üzerinde mutlak surette tasarruf hakkına sahip olsa da Türk Ceza Kanunu 103 ve 104. maddelerinde çocukların bu konudaki rıza açıklamalarını kabul etmemiştir.

*Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenleyen TCK'nın 109. maddesinde ise mağdurun rıza açıklama ehliyetini belirleme noktasında bir yaş sınırı getirilmemiştir. Bu halde yaşı küçük mağdurun rızasının failin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırıp kaldırmayacağı, **failin amacının** toplumda kabul gören bir davranış ya da genel ahlak kurallarına uygun olup olmadığı nazara alınarak belirlenmelidir. Bu anlamda küçük yaştaki çocuğun gideceği yere bırakılması ya da çocuğun ailesini evde bulamadığı için komşularına gitmesi örneklerinde olduğu gibi **kişinin meşru amaçla hareket ettiği durumlarda yaşı küçük çocuğun rızası geçerli olacak, kişinin haksızlık bilinciyle hareket ettiği hallerde ise yaşı küçük çocuğun rızası geçerli olmayacaktır.** Bu sebeple yaşı küçük mağdurun rızasının failin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırıp kaldırmayacağı her olayın özelliğine göre değerlendirilip belirlenmelidir.*

Sanığın, evlenmek amacıyla yaşı küçük mağdureyi rızasıyla kendi evine götürerek bir süre alıkoyduğu sabit bulunan olayda, mağdurenin rızası, haksızlık bilinciyle hareket eden sanığın ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Dolayısıyla yaşı küçük mağdurenin hukuken geçerli sayılan rızası bulunmadan gerçekleşen bu eylem kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmaktadır.”

Ceza Genel Kurulu’nun bu tespit ve değerlendirmeleri, bizim açıklamalarımız ile uyum içindedir. Ancak belirtmek gerekir ki, söz konusu olayla ilgili olarak kararda S’nin anne ve babasının ceza sorumluluğunun olup olmadığı tartışılmamıştır.

Ayrıca bkz. CGK, **24.10.2017**, E. 2014/14-731, K. 2017/429.

İkinci ihtimal: Cebir, tehdit ve hile olmaksızın onbeş yaşını tamamlamış olan bir çocuğun, cinsel ilişkide bulunmak amacıyla, bir yere götürülmesi, bir yerde alıkonulması halinde dahi, kanaatimizce, amacın gayrimeşruluğu sebebiyle, fiil yine kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halini oluşturacaktır.

Ancak, hukuk uygulamamız bu durumda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun değil, TCK, m. 234, f. 3’de tanımlanan suçun oluştuğunu kabul etmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **9.6.2015** tarihli ve E. 2013/14-668, K. 2015/202 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, Şaban, 21.2.2010 tarihinde karakola giderek 17 yaşında olan kızı Saadet’in 20.2.2010 tarihinde evden kaçtığına ilişkin ihbarda bulunması üzerine yapılan

Örnek 4. Onbeş yaşını doldurmuş olan çocuklar cinsel farkındalık dönemine girmiş olmakla birlikte, henüz kişiliklerinin yeterince gelişmemiş olması, başkalarıyla cinsel ilişkiye girmenin sonuçlarını yeterince kavrayacak bir sorumluluk duygusuna sahip olmamaları dolayısıyla; bu çocuklarla cinsel ilişkide bulunulması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu ilişkinin rızaya dayalı olarak gerçekleştirilmesi, *fiili suç olmaktan çıkarmayacak ve kişinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır*. Başka bir deyişle, yeni TCK'nın 104. maddesi, onbeş yaşını tamamlamış olan çocuklara, bir başkasıyla cinsel ilişkide bulunmak yönünde cinsel bütünlükleri üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi tanınmamıştır. Bu nedenle, **onbeş yaşını tamamlamış olan çocuğun rıza açıklaması, reşit kılınmadığı sürece, kendisiyle cinsel ilişkide bulunan bir başkasının fiilini hukuka uygun hale getirmemektedir**⁵⁴².

Söz konusu suç ancak onsekiz yaşını doldurmuş olan kişiler tarafından işlenebilir. Buna göre, söz konusu suçun faili, onsekiz yaşını doldurmuş olan bir kişi; mağduru ise, onbeş yaşını doldurmuş olmakla birlikte henüz onsekiz yaşını doldurmamış olan bir kişi olabilir. Bu suç bakımından, fail veya mağdurun cinsiye-ti önemli değildir (TCK, m. 104).

Buna karşılık, onbeş yaşını doldurmuş olmakla birlikte henüz onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin birbiriyle olan cinsel ilişkileri, ceza hukukunun mü-

araştırmada Saadet'in Mehmet'in yanında olduğu tespit edilir ve 2.3.2010 tarihinde Mehmet ile Saadet birlikte kaldıkları evde yakalanırlar.

Bu olay sebebiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde alınan ifadelerinde Saadet, evden kaçtıktan sonra Mehmet'in yanına gittiğini, bir kez kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini, yaklaşık 12 gün boyunca isteyerek Mehmet'in yanında kaldığını beyan etmiştir. Mehmet de, sorgu ve ifadelerinde Saadet'i sevdiğini, ailesinden istediğini, fakat vermediklerini, bunun üzerine Saadet'in evden kaçarak yanına geldiğini, rızasıyla bir kez ilişkiye girdiklerini ve ailesine haber vermediğini beyan etmiştir.

Ceza Genel Kurulu, söz konusu olayda, "mağdure" olarak değerlendirilen Saadet'in kendi isteği ve kanuni temsilcisinin (babasının) haberi olmadan evden kaçarak Mehmet'in yanına gitmesi, Mehmet'in de yetkili makamlara veya ailesine bilgi vermeden Saadet'i yanında tutması karşısında, TCK, m. 234, f. 3'te tanımlanan "**çocuğun alıkonulması suçunun tüm unsurları itibarıyla oluştuğu**"nu kabul etmiştir.

Dikkat edilmelidir ki, bu olayda Saadet, cinsel ilişkiye girdiği Mehmet hakkında şikayette bulunmuş değildir.

Aynı yönde kararlar için bkz. 14.CD, **22.3.2016**, E. 2014/3737, K. 2016/2801; 14.CD, **19.1.2016**, E. 2014/617, K. 2016/401; 14.CD, **4.11.2015**, E. 2014/59, K. 2015/10200.

Dikkat edilmelidir ki, söz konusu suçun mağduru, çocuk üzerinde velayet veya vesayet yükümlülüğü altında bulunan kişidir; yani çocuğun bakım ve gözetimiyle yükümlü (çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu) olan gerçek kişidir. Oysa söz konusu kararlarda, mağdur olarak çocuğa işaret edilmektedir.

⁵⁴² Onbeş yaşını tamamlamış olan çocuklarla cinsel ilişkiye giren kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için, mağdurun şikayette bulunması gerekir. Bu itibarla, **mağdurun şikayette bulunmaması veya bilahare şikayetten vazgeçmiş olması, fiili hukuka uygun hale getirmemektedir**. Bir ceza muhakemesi hukuku müessesesi olan şikayet, sadece bir soruşturma ve kovuşturma koşulu oluşturmaktadır.

dahale alanı dışında kalmaktadır. Bu grup yaş küçükleri arasındaki cinsel ilişki sorunu, ancak toplum ve aile disiplini çerçevesinde çözümlenebilir.

18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla TCK'nın 104. maddesinde yapılan değişiklikle maddeye ikinci fıkra olarak eklenen hüküm, bu yorumumuzu teyit etmektedir:

“Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Reşit olan bir kişinin aralarında evlenme yasağı bulunan ve onbeş yaşını tamamlamış olan bir çocukla cinsel ilişkiye girmesi, bir **fücur** fiili (**ensest ilişkisi**) olarak **re'sen** soruşturulabilir bir **suç** oluşturmaktadır.

Aralarında evlenme yasağı bulunan iki reşit kişinin karşılıklı rızaya dayalı olarak birbirleriyle cinsel ilişkiye girmesi halinde, rızanın varlığı bu fiili hukuka uygun hale getirmemektedir. TCK'nın halen yürürlükte olan şekli itibarıyla reşit kişiler arasındaki **fücur** fiili (**ensest ilişkisi**) suç olarak tanımlanmamış ise de, bu ilişki hukuka uygun değildir.⁵⁴³

Örnek 5. Evlilik birliğinde eşlerin birbirlerine karşı olan *sadakat yükümlülüğü* bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün ihlali mahiyetini taşıyan zina, bu nedenle haksız fiildir.⁵⁴⁴ Eşlerden birinin zina konusundaki rıza açıklamasının hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.⁵⁴⁵

⁵⁴³ Bu fiillerin de suç olarak tanımlanması bakımından bkz. Alman CK, § 173.

⁵⁴⁴ “Evlilik birliğinde sadakatte kadın ve erkek aynı ölçüde yükümlüdürler. Evlenmek ile karı ve koca sıfatını alan eşleri bu müessese içinde sadakat açısından farklı konumlarda görmek mümkün değildir.”

“Karşılıklı sadakat yükümlülüğü bakımından karı ile koca arasında fark bulunmamaktadır.”

“Konusunu evlilik dışı cinsel ilişkinin oluşturduğu zina, öğretide de kabul edildiği gibi, evlilik bağının eşlere yüklediği cinsel bağlılığın ihlali olarak tanımlanabilir.”

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. **Anayasa Mahkemesinin** 23.9.1996 tarihli ve 15/34 sayılı; 23.6.1998 tarihli ve 3/28 sayılı; 13.7.1999 tarihli ve 24/30 sayılı **Kararları**.

⁵⁴⁵ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **17.2.2015** tarihli ve E. 2014/1-572, K. 2015/2 sayılı Kararında yer alan şu açıklamalar, düşündürücü bulunmuştur:

“Mağdurun rızası cinsel saldırı suçu bakımından hukuka uygunluk nedeni olduğundan TCK'nın 26/2. maddesi uyarınca hukuken geçerli olan rıza cinsel saldırı teşkil eden eylemleri hukuka uygun hale getirecektir.”

Evli kadının kocası dışında başka bir erkekle cinsel ilişkiye girme yönündeki rızasının varlığı, cinsel saldırı suçunun oluşmasına engel teşkil edecektir. Zira bu durumda, reşit kadın cinsel ilişkiye girme bağlamında zorlanmış veya aldatılmış değildir. Ancak, bu durumda, evli kadına karşı iradesini ifsat edecek herhangi bir davranışta bulunulmamış olması, evli kadının kocası dışında başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi yönündeki rızası, bu ilişkiyi hukuka uygun hale getirmez. Bu bağlamda **rızanın varlığı, cinsel saldırı suçunun oluşmasına engel teşkil eder, ancak fiile hukuka uygunluk vasfı izafe etmez.**

Örnek 6. Yeni TCK sisteminde, 765 s. TCK'dan (m. 436) farklı olarak, kadının yaşı ne olursa olsun, fuhuş icrası yönündeki rızasına hukuki değer izafe edilmemektedir (m. 227).

“Evlilik birliğinde aile bireylerinden ... birinin rızası varsa,” bu rızaya dayalı olarak konuta giren kişinin davranışı konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturmaz. “Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.” (m. 116, f. 3). “Buna göre, evlilik birliğinde aile bireylerinden birinin rızasının olması, söz konusu suça ilişkin hukuka aykırılık vasfını ortadan kaldırır. ... Ancak bu hâllerde konuta girişin hukuka uygun sayılabilmesi için, rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. Bu bakımdan örneğin, konuttaki teknik bir arızanın tamiri için, diğerinin bilgisi olmaksızın, eşlerden birinin tamircinin konuta girmesine rıza göstermesi hâlinde, bu rıza geçerli bir rıza olarak kabul edilmelidir. Buna karşılık, eşlerden birinin bir başkasını zina yapmak üzere konuta kabul etmesi durumunda, bu kişinin konuta girmesine gösterilen rızanın, geçerli bir rıza olarak kabul edilmesi imkansızdır ve bu durumda diğer eşe karşı işlenmiş konut dokunulmazlığını ihlâl suçu söz konusudur.” (m. 116 gerekçesi)⁵⁴⁶.

Ekskurs 5. Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler⁵⁴⁷

I. İnsan, sağlıklı bir hayat sürme hakkına sahiptir. Bu itibarla, herhangi bir sebeple sağlık şartları bozulmuş olan insanın, kendisine sağlığını iyileştirici

⁵⁴⁶ Yargıtay'ın da bu yönde içtihatları bulunmaktadır:

«Mağdurenin sanıkları suçüstü yakalatmak amacıyla onları eve çağırıp durumu zabıtaya bildirdiği; tertibat alan zabitanın saat 24.00 sularında mağdurenin konutu eklentisine (avluya) giren sanıklardan Osman'ı yakaladığı, diğer sanık Zafer'in kaçtığı ... olayda, Özel Daire ile Yerel mahkeme arasındaki *uyuşmazlık*; eşi Almanya'da olan mağdurenin davetinde samimi olduğuna inanıp, onunla gayrimeşru münasebetlerde bulunmak amacıyla evin eklentisine giren sanıkların fiillerinin konut dokunulmazlığını bozma suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Maddi olayda, sanıkların gayrimeşru münasebetlerde bulunmak amacıyla mağdurenin konutu eklentisine girdikleri tesbit edildiğine göre, **mağdurenin rızası olsa dahi kocasının rızası(n) olamayacağı** aklen ve adeten açıktır. Kaldı ki **mağdurenin gerçek iradesi, sanıkları eve davet olmayıp, onları suçüstü yakalamaya yöneliktir.** Bu itibarla; sanıkların, mağdurenin davetinde samimi olduğu inancıyla da olsa, gayrimeşru münasebetlerde bulunmak amacıyla onun evi eklentisine girmeleri, **konut dokunulmazlığını bozma suçunu oluştur**ur: CGK., 29.5.1995, 4-146/170 (YKD, Eylül 1995, sh. 1462 vd.).

«Fail, sözelimi zina için eşin rızası ile girdiği yerde bu türden hukuka aykırı davranışlarda bulunduğu anda..., evlilikte sadakat ihlâl edilecektir ve öbür eşin konuta girmeye ya da oradan kalmaya razı olmayacağı varsayılmıştır. (Bu suçun) faili de **ikidir**. Bunlar, zina girişiminde bulunan kişiler, yani **evli eş** ve suçu ortağıdır. Mağdur ise, öbür eştir»: Sami SELÇUK, CGK'nın 11.3.1991 tarihli ve 4-25/67 sayılı Kararına muhalefet şerhi (YKD, Ocak 1992, sh. 106).

⁵⁴⁷ Bu paragraf altındaki açıklamalar için ayrıca bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi*, 3. bası, Adalet Bakanlığı yayını, Ankara, Ocak 2006, sh. 284 vd; aynı yazar: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku*, Ankara, Eylül 2006, sh. 347 vd.; aynı yazar: *Hekimlik Mesleğinin İcrası ve Ceza Sorumluluğu*, in: Ankem Dergisi, yıl 2006, cilt 20, Ek 2, sh. 10 vd.; aynı yazar: *Hekimin Tedavi Nedeniyle Ceza Sorumluluğuna İlişkin Röportaj*, in: Sağlıkta Nabız Dergisi, yıl 2006, sayı 18, sh. 4 vd.; aynı yazar: *Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler*, in: SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos 2007, sayı 3, sh. 76 vd.

tıbbî müdahalede bulunulmasını talep etmesi, bu hakkın kullanılmasından ibarettir.

Kişi, sağlığının yerinde olup olmadığının yani hasta olup olmadığının, hasta ise ne tür bir hasta olduğunun belirlenmesi (**teşhis, tanı**) ve maruz kaldığı hastalığın iyileştirilmesi (**tedavi**) **amacıyla** kendisine **tıbbî müdahalede** bulunulmasına **rıza** göstermek (**onam** vermek) hakkına sahiptir⁵⁴⁸.

Ancak, **salt** bu **rıza, yapılan tıbbî müdahalenin hukuka uygunluğunu sağlama bakımından yeterli değildir.**

Kişinin, tıbbî müdahaleye ilişkin olarak açıkladığı rızanın hukuken bir değer taşıyabilmesi için, uygulanacak olan teşhis ve tedavi yönteminin mahiyet, etki ve sonuçları bakımından yeterince bilgilendirilmiş olması gerekir: “**aydınlatılmış onam**”⁵⁴⁹.

Bu bakımdan, uygulanacak teşhis ve tedavi yönteminin mahiyet, etki ve sonuçları ile ilgili olarak gerekli bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleştirilen tıbbî müdahale “rıza”ya dayalı olsa bile, bu “rıza” hukuken geçersizdir. Dolayısıyla, hukuken geçerli olmayan bir rızaya dayalı olarak yapılan tıbbî müdahale, teşhis ve tedavi amacıyla da olsa, hukuka aykırıdır. Aşağıda açıklayacağımız üzere, kanunun tabibe kişinin rızasının olmamasına rağmen tedavi yükümlülüğü getirdiği haller ile zorunluluk hali dışında, geçerli rızaya dayalı olmayan tıbbî müdahaleler, ceza sorumluluğunu gerektirir. Hatta, yapılan tıbbî müdahale sonucunda kişinin hastalığının iyileştirilmiş olması, bu ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bazı hallerde, rıza açıklamasına hukuki değer izafesi, usule ilişkin belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı kılınabilir. Mevzuatımızda **rıza açıklamasının ne suretle yapılacağı** konusunda çeşitli hükümler bulunmaktadır.

Örneğin, 11.4.1928 t. ve 1219 s. “*Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun*”un 70. maddesine göre, “*Tabipler, dış tabipleri ve dışçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise*

⁵⁴⁸ Teşhis ve tedavi amacına yönelik olarak kişinin açıkladığı rızanın kapsam ve mahiyeti hakkında ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. 4. HD, 7.3.1977, 6297/2541 (YKD, Haziran 1976, sh. 905 vd.). Söz konusu karara ilişkin değerlendirme için bkz. ÜNVER, Yener: *Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk*, İstanbul, 1998, sh. 192 vd.

⁵⁴⁹ “Aydınlatılmış onam” kavramıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. HAKERİ, Hakan: *Tıp Hukuku*, Ankara 2007, sh. 103 vd.; ERMAN, Barış: *Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu*, Ankara, 2003, sh. 99 vd. Keza, “*Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi*” (“*Avrupa Biyo-Tıp Sözleşmesi*”) hükümleri çerçevesinde aydınlanmış onam kavramıyla ilgili açıklamalar için bkz. KÖK, Ahmet Nezi: *İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Göre Aydınlatma ve Rıza*, in: Kamu Hukuku Arşivi (KHUKA), Kasım 2005, yıl 8, sh. 116 vd.; GÖKCAN, Hasan Tahsin: *Perinatolojide Tıbbî Uygulama Hataları Nedeniyle Cezai Sorumluluk*, in: 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-29 Nisan 2007, Antalya, sh. 109.

veli veya vasisinin evveleminde **muvaafakatini** alırlar. Büyük ameliyei cerrahiye-ler için bu muvaafakatin **tahriri** (yazılı) olması lazımdır.”⁵⁵⁰.

II. Belirtmek gerekir ki, tıbbî müdahaleye rıza göstermeyen bir hastaya buna rağmen tedavi amaçlı müdahale girişimi insan onuruyla bağdaşmaz. Aklen sağlıklı, bilinci açık olan hasta kendisine karşı tedavi uygulanmasını reddettiğinde, meselâ bağlı olduğu teknik cihazın çıkarılmasını istemek gibi hayatını sürdürücü tedaviyi artık kabul etmediğinde; buna rağmen, iyileştirilmesini veya hayatta kalmasını sağlamaya yönelik olarak bu kişiye tıbbî müdahalede bulunulmamalıdır.⁵⁵¹

Hatta, hastanın rıza göstermediği bir tıbbî müdahalenin başarı şansı da tartışılabilir. Bu nedenle tıbbî müdahalenin gerekli olduğuna hastanın kani olması, ikna edilmesi gerekir. İkna girişimine rağmen şuuru açık olan ve tedaviye rıza göstermeyen hastaya tıbbî müdahalede bulunulamaz.⁵⁵² Bu itibarla, şuuru yerinde olan hastanın artık istememesi dolayısıyla kendisine karşı tedavi uygulanmasından, hayatını devamı için gerekli olan teknik cihazla olan bağlantısının kesilmesi gibi hayatını sürdürücü tedaviden sarfinazar eden sağlık görevlileri ceza hukuku bakımından sorumlu tutulamazlar.⁵⁵³

III. Rıza göstermemesine rağmen, kişiye tıbbî müdahale, ancak **kamu sağlığı** gereğiyle yapılabilir. Başka bir deyişle, **kamu sağlığını korumak için, rıza göstermemesine rağmen, elverdiği ölçüde kişiye tıbbî müdahalede bulunulabilir**.^{554,555,556}

⁵⁵⁰ Benzer hükümler için bkz. TCK, m. 90; f. 2, 4; 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılması ve Nakli Hakkında Kanun”, m. 6; “Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük”, m. 13.

⁵⁵¹ “Aktif ötenazi” ve “pasif ötenazi” ayırımıyla ilgili olarak bkz. DÖNMEZER, Sulhi: *Kişilere ve Mala Karşı Cürümler*, 13. bası, 1990, no. 22; BAYRAKTAR, Köksal: *Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu*, İstanbul, 1972, sh. 150; CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem: *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, 3. bası, İstanbul, 2005, sh. 330 vd.; HAKERİ, Tıp Hukuku, sh. 304 vd.

⁵⁵² 1219 s. “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”, m. 70; “Hasta Hakları Yönetmeliği”, m. 5, bend d, m. 24 vd.; “Hekimlik Meslek Etiği Kuralları”, m. 26.

⁵⁵³ DÖNMEZER, *Kişilere ve Mala Karşı Cürümler*, no. 23.

⁵⁵⁴ Kamu sağlığını gerektiren durumlarda hekimlerin tedavi yükümlülüğünün yanı sıra, kişilerin **tedaviye katlanma yükümlülüğü** bulunmaktadır. Bilgi için bkz.

ÖZGENÇ, İzzet: COVID-19 Salgınının Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku ve Milletlerarası Hukuk Alanında Sebebiyet Verdiği veya Verebileceği Sorunlar ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri, in: TÜBA Covid-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu, Covid-19 Salgını Dolayısıyla Ulusal veya Uluslararası Alanda Ortaya Çıkan/Çıkabilecek Hukuki Sorunların Çözümüne Yönelik Öneriler Raporu, Türkiye Bilimler Akademisi yayını, Ankara, Temmuz 2020, sh. 11 vd.;

<http://tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/TUBA-978-605-2249-47-5.pdf> (erişim tarihi 9.12.2021).

<http://tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/TUBA-978-605-2249-52-9.pdf> (erişim tarihi 9.12.2021).

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre bildirim yükümlülüğü kapsamında olan hastalıklarla ilgili olarak kişilere, tabip tarafından yapılacak **teşhis ve tedaviye** yönelik muameleye

katlanmak yükümlülüğü getirmiştir (1593 s. K., m. 67). Hatta bu yükümlülüğe aykırı davranan hastalarla ilgili olarak, yaptırım öngörülmüştür (1593 s. K., m. 287). Diğer bir deyişle, bu durumlarda tabipler açısından **teşhis ve tedavi yükümlülüğü** bulunmaktadır.

Keza, “*frengi, belsoğukluğu ve yumuşak şankır*” hastalıklarına müptela olan kişilerle ilgili olarak **tedavi olma yükümlülüğü** mevcuttur (1593 s. K., m. 103). Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiler, **zorunlu** olarak **tedaviye** tabi tutulur (1593 s. K., m. 107).

Kişilerle ilgili olarak belli hastalıklara karşı **aşı olma yükümlülüğü** getirilmiştir (1593 s. K., m. 88, 90).

Bütün bu düzenlemeler karşısında **AİDS** hastalığı ile ilgili olarak şu tespit ve önerilerde bulunulabilir:

1. AİDS hastalığı, bulaşıcı bir hastalıktır.
2. Bu hastalıkla ilgili olarak karantina tedbirleri alınmalıdır.
3. Bu tedbirler kapsamında, hastalığı ile ilgili olarak kişinin yakınlarına bilgi vermek gerekir.
4. Hasta yakınlarının bu hususta bilgilendirilmesi, 5237 s. TCK’nın kişisel verileri bir başkasına hukuka aykırı olarak verme fiilini cezalandıran 136. maddesindeki suç oluşturmaz.

Ancak, bu hastalıkla ilgili olarak alınması gereken karantina tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından genel bir düzenleyici işlem yapılmasına ihtiyaç bulunduğu kanısındayız.

⁵⁵⁵ “*Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik*” olarak tanımlanan aşının (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 10. baskı, Ankara, 2005, sh. 136) uygulaması, önleyici nitelikte bir tıbbi müdahaledir. Başka bir ifadeyle, aşı uygulaması, hastaya tedavisi için yapılmaz.

Bulaşıcı hastalıklara karşı hastalığın özelliklerine göre belirlenen toplumun asgari bir oranının aşılınması ile, ilgili hastalığın toplum sağlığını tehlikeye sokma ihtimali azaltılabilir ve hatta ortadan kaldırılabilir.

1593 s. Kanunun mevcut hükümlerine göre birtakım idari tedbirler alınabilirse de, zorunlu aşı uygulaması yapılamaz.

Zorla aşı yapmak, kişinin vücut bütünlüğüne müdahaledir. Ancak, kişinin vücut bütünlüğüne her müdahale, bir hak ihlaline sebebiyet vermez. Kamu sağlığının korunması amacıyla, kişilerin belirli hak ve özgürlüklerine müdahale edilebilir. Bu amaçla kişiler teşhis ve tedaviye, hatta, henüz hasta olmamakla birlikte, aşılama muamelesine tabi tutulabilirler. Bunun için temel koşul, bu müdahalenin kanuni dayanağının olmasıdır.

Anayasaya göre, “*tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz*” (m. 17, f. 2).

Anayasa Mahkemesi, “zorunlu aşı” uygulaması için sadece tıbbi zorunluluğun varlığını yeterli görmemektedir. Bu zorunluluğun yanı sıra, kanuni dayanağın da olması gerekmektedir. Buradaki kanuni dayanaktan neyin anlaşılması gerektiği de bir sorundur. Anayasa Mahkemesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda (m. 57 ve m. 88 vd.) sayılan belirli hastalıklarla sınırlı olarak “zorunlu aşı” uygulaması yapılabileceğini kabul etmiştir (Anayasa Mahkemesi’nin 11.11.2015 tarihli ve 2013/1789 Bireysel Başvuru sayılı Kararı (RG: 24 Aralık 2015/29572), kn. 71, 72; ayrıca bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 21.11.2017 tarihli ve 2014/5629 Bireysel Başvuru sayılı Kararı, kn. 52, 53; Anayasa Mahkemesi’nin 23.3.2016 tarihli ve 2013/7246 Bireysel Başvuru sayılı Kararı, kn. 75, 76). Bu içtihadı göre, bir hastalık dolayısıyla “zorunlu aşı” uygulaması yapılabilmesi için bu hastalığın kanunla belirlenmesi gerekecektir.

Anayasa Mahkemesinin bu içtihadına göre, 1593 sayılı Kanunda açıkça sayılmadıkları için, kamu sağlığını tehlikeye sokma özelliği taşımalarına rağmen, örneğin “HepB, DaBT, İPA, Hib ve KPA” gibi hastalıklara karşı “zorunlu aşı” uygulaması yapılamayacaktır (Anayasa Mahkemesi, BB 2013/1789, kn. 71).

Bu yaklaşımın doğru olmadığını belirtmek gerekir. Anayasa Mahkemesi, bu değerlendirmelerde, 1593 s. Kanun, m. 64 hükmünü göz ardı etmiştir. Zira söz konusu madde hükmü, bu Kanunda (m. 72) belirtilen tedbirlerin bilahare ortaya çıkan ve kamu sağlığı bakımından tehlike oluşturan hastalıklarla ilgili olarak da uygulanabilmesine imkân tanımaktadır. Başka bir ifadeyle, 1593 sayılı Kanun hükümlerine göre, kamu sağlığı bakımından alınması gereken tedbirler, bu Kanunda sayılan hastalıklarla sınırlı tutulmamıştır. Bu hastalıklar **örnekleme** yöntemiyle belirlenmiştir. Hatta işaret etmek gerekir ki, zaman içinde alınan sağlık tedbirlerinin etkisiyle, bu hastalıklardan bir kısmının kamu sağlığı bakımından tehlikelilik özelliği ortadan kalkmıştır. Bu itibarla, **COVID-19** gibi, bilahare ortaya çıkan ve kamu sağlığı bakımından tehlikelilik özelliği taşıdığı tespit edilen hastalıkla ilgili olarak da bu Kanunda belirtilen tedbirler alınabilir (m. 64).

1593 sayılı Kanun bakımından **sorun** teşkil eden husus, Kanunda yer verilmiş olan, “*hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbiki*” ifadesidir (m. 72). Öncelikle belirtmek gerekir ki, **aşı uygulaması, hastaya değil, kişilerin belirli bir hastalığa karşı korunması amacıyla yapılan bir tıbbi müdahaledir.**

Söz konusu Kanun, **çiçek aşısı** uygulaması (m. 88) hariç olmak üzere, tıbbi müdahale ve tedavi yükümlülüğünü sadece **kamu sağlığı bakımından tehlikeli olan bulaşıcı hastalığa maruz kaldığı tespit edilen** veya **bu hususta kendisinden şüphelenilen kişiler** bakımından getirmiştir. Bu itibarla, mevzuatımız, tehlikeli salgın hastalık sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmiş olsa bile, salgın hastalığın sirayet ettiğinden şüphe edilmeyen kişilere tıbbi müdahale yetkisi vermemektedir.

Sonuç itibarıyla belirtebiliriz ki, **1593 sayılı Kanun**, bulaşıcı hastalıktan korunmak amacıyla da olsa, bulaşıcı hastalığa karşı bir tedbir de olsa, **hasta olduğu hususunda somut şüphe sebebi bulunmayan kişilere tıbbi müdahalede bulunma yetkisi vermemektedir.** Bunun tek istisnasını, **çiçek aşısı** uygulaması (m. 88) oluşturmaktadır. Tehlikeli salgın hastalığın toplumda sirayet ettiği kişilerin varlığı, genel bir bulaş tehlikesini ifade etmektedir. Ancak, söz konusu Kanun, bu **genel bulaş tehlikesine binaen, hasta olup olmadığına bakılmaksızın herkese tıbbi müdahalede bulunma yetkisi vermemektedir.** Bu itibarla, mer’i mevzuatımız, **çiçek aşısı** uygulaması (m. 88) hariç olmak üzere, **kişilerin iradesi olmadan aşı uygulamasına izin vermemektedir.**

Bir varsayım olarak mevzuatımızın “zorunlu aşı” uygulamasına izin verdiği kabul edilse bile, bunun fiili uygulanabilirliği olamaz; yani, kişi istemediği takdirde, zor kullanılarak aşılanması yoluna gidilemez.

Ancak, COVID-19 gibi tehlikeli salgın hastalığa karşı alınması gereken tedbirler cümlesinden, örneğin toplu taşıma araçlarından yararlanabilmek, uçakla seyahat edebilmek, eğitim öğretim hizmetlerinden mevcutlu olarak yararlanabilmek, bir toplantıya mevcutlu olarak katılabilmek gibi, belirli hizmetlerden yararlanabilmek, belirli faaliyetlere iştirak edebilmek için, **aşı yaptırmak bir koşul olarak aranabilir.** Bunun için bir KANUNİ DÜZENLEME YAPILMASINA GEREK BULUNDUĞU belirtilmek gerekir. Bu düzenlemede, kişinin, aşı yaptırmadığı için, bir hizmetten yararlandırılmaması, bir hakkı kullanmasının engellenmesi, bir hukuka uygunluk sebebi olarak tanımlanabilir. Hatta, aşı yaptırmadığı için bir kamu görevlisinin çalıştığı kamu kurumuna, bir işçinin çalıştığı işyerine kabul edilmemesi, mazeretsiz göreve/işe gelmemek olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, umumi hıfzıssıhha meclisleri, kamu sağlığı bakımından tehlikeli olan bulaşıcı hastalıktan korunmak amacıyla da olsa, aşı zorunluluğu ihdas edemez (ÖZGENÇ, İzzet: “Zorunlu Aşı Uygulaması Sorunu Üzerine”, in: <https://izzetozgenc.com/makale/zorunlu-asi-uygulamasi-sorunu-uzerine> [yayına giriş tarihi 27.12.2020; erişim tarihi 9.12.2021]).

⁵⁵⁶ **Fuhşa sürüklenen kişi**, yaşı ne olursa olsun, yeni TCK’nın sisteminde, fuhuş suçunun **mağduru** olarak kabul edilmiştir. TCK’nın 227. maddesinin sekizinci fıkrasında “**Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulabilir.**” hükmüne yer verilmiştir. Dikkat edilmelidir ki, bu hükümde de suçun mağduru kişiler açısından **tıbbi müdahaleye katlanma yükümlülüğü** getirilmiştir. Bu itibarla, fuhşa sürüklenen kişi, bulaşıcı bir hastalık taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla tıbbi müdahaleye katlanmakla yükümlüdür. Bulaşıcı bir

IV. Keza, işaret etmek gerekir ki, teşhis ve tedaviye yönelik müdahale için kişi her zaman rıza açıklamasında bulunabilecek durumda olmayabilir. Bu gibi durumlarda, rızasının olup olmadığını araştırmaya gerek olmaksızın, kişiye tıbbî müdahalede bulunulması gerekmektedir. Çünkü, tabiplik mesleğini icra eden veya icra etmek hususunda yetkiyle donatılan kişi⁵⁵⁷, tıbbî müdahaleye ihtiyaç duyan bir kimseye iyileştirilmesi amacına matuf gerekli müdahalede bulunmakla **yükümlüdür**⁵⁵⁸. Bu yükümlülüğün varlığı halinde, gerçekleştirilen tıbbî müdahale, **görevin yerine getirilmesi** dolayısıyla **hukuka uygundur**. Bu gibi du-

hastalığının varlığının tespiti halinde, ayrıca tedaviye katlanma yükümlülüğü söz konusu olacaktır. Yapılan muayene sonucunda, fuhşa sürüklenen kişinin bulaşıcı hastalığının bulunmadığının anlaşılması halinde ise, gerekli olduğu takdirde, psikolojik terapiye tabi tutulabilecektir. Dikkat edilmelidir ki, fuhşa sürüklenen kişinin psikolojik terapiye tabi tutulabilmesi için, rızasının olup olmamasından ziyade, psikolojisinin böyle bir tedaviyi gerekli kılması önem taşımaktadır. Nitekim, TCK'nın 227. maddesinin sekizinci fıkrasında 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin **gereğince**de şu açıklamaya yer verilmiştir: “5237 sayılı Kanunun 227 maddesinin sekizinci fıkrasında fuhuş suçunun mağduru konumundaki kişilerin, *örneğin bulaşıcı hastalık taşımaları dolayısıyla tedaviye tabi tutulmasının yanı sıra ya da buna ihtiyaç duyulmaması halinde sadece psikolojik terapi uygulanmasını sağlayacak düzenleme* yapılmıştır” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1255, sh. 19).

İşaret etmek gerekir ki, fuhşa sürüklenen kişinin muayenesinin ve gerektiği takdirde tedavisinin yapılabilmesi için hakim kararına gerek bulunmamaktadır. Fuhuş suçunun işlendiği hususunda ortaya çıkan şüpheye bağlı olarak soruşturmayı yürüten **C. savcısı**, soruşturma kapsamında söz konusu suçun mağduru konumundaki kişilerin bulaşıcı hastalığının olup olmadığının tespiti ve tıbben gerekli olması halinde tedaviye ve psikolojik terapiye tabi tutulması için gerekeni yapmakla **yükümlüdür**.

⁵⁵⁷ Ülkemizde tabiplik mesleğinin icrası için gerekli şartlarla ilgili olarak bkz. 11.4.1928 t. ve 1219 s. “*Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun*” (RG: 14 Nisan 1928/863).

⁵⁵⁸ Türkiye tarafından da onaylanan 4.4.1997 tarihli “*Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi*”nin (“**Avrupa Biyo-Tıp Sözleşmesi**”nin) (RG: 20 Nisan 2004/25439) “*Muvafakat*” başlıklı II. Bölümünde konumuzla ilgili olarak şu hükümler yer almaktadır:

Madde 5. (Genel Kural)

Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir.

Bu kişiye, önceden, müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilecektir.

İlgili kişi, muvafakatini her zaman, serbestçe geri alabilir.

Madde 6. (Muvafakat verme yeteneği bulunmayan kişilerin korunması)

1. Aşağıda, 17 ve 20. maddelere tâbi olmak koşuluyla, muvafakat verme yeteneği bulunmayan bir kimse üzerinde tıbbî müdahale, sadece onun doğrudan yararı için yapılabilir.

2. Kanuna göre bir müdahaleye muvafakatini verme yeteneği bulunmayan bir küçüğe, sadece temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen makam, kişi veya kuruluşun izni ile müdahalede bulunabilir.

Küçüğün görüşü, yaşı ve olgunluk derecesiyle orantılı bir şekilde, gittikçe daha belirleyici bir etken olarak gözönüne alınacaktır.

3. Kanuna göre, akıl hastalığı, bir hastalık veya benzer nedenlerden dolayı, müdahaleye muvafakat etme yeteneği bulunmayan bir yetiškine, ancak temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen kişi veya makamın izni ile müdahalede bulunulabilir.

İlgili kişi mümkün olduğu ölçüde izin verme sürecine katılacaktır.

4. Yukarıda 2 ve 3. paragraflarda belirtilen temsilci, makam, kişi veya kuruluşa, aynı şartlarda, Madde 5'te belirtilen bilgi verilecektir.

5. Yukarıda 2 ve 3. paragraflarda belirtilen izin, ilgili kişinin en fazla yararı bakımından her zaman geri çekilebilir.

Madde 7. (Akıl hastalığı olan kişilerin korunması)

Gözetim, denetim ve başka bir makama başvurma süreçleri dahil, kanun tarafından öngörülen koruyucu şartlarla bağlı olmak üzere, ciddi nitelikli bir akıl hastalığı olan kişi, yalnızca böyle bir tedavi yapılmadığı takdirde sağlığına ciddi bir zarar gelmesinin muhtemel olduğu durumlarda, muvafakatı olmaksızın, akıl hastalığının tedavi edilmesini amaçlayan bir müdahaleye tâbi tutulabilir.

Madde 8. (Acil durum)

Acil bir durum nedeniyle uygun muvafakatin alınamaması halinde, ilgili bireyin sağlığı için tıbbî bakımdan gerekli olan herhangi bir müdahale derhal yapılabilir.

Madde 9. (Önceden açıklanmış istek)

Müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek bir durumda bulunmayan bir hastanın, tıbbî müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış olduğu istekler gözönüne alınacaktır.

İşaret etmemiz gerekir ki, söz konusu Sözleşmenin onaylanması 3.12.2003 tarihli ve 5013 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Sözleşme, 26.11.2006 tarihi itibarıyla **İngiltere, Almanya, Rusya Federasyonu, Avusturya ve İrlanda** tarafından 2 Ağustos 2007 tarihi itibarıyla **imzalanmamıştır. Fransa, İtalya, İsviçre, Ukrayna, Polonya ve Finlandiya** tarafından imzalanmış olmakla birlikte, 2 Ağustos 2007 tarihi itibarıyla **onaylanmamıştır**. Sözleşme, Türkiye'nin yanı sıra, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Estonya, Danimarka ve İspanya gibi ülkeler tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.

1219 s. “**Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun**”nun 70. maddesi hükmüne göre,

«... *Tabipler, dış tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın ... evvele-
mirde muvafakatını alırlar. ... (Ancak,) ... üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir
olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.*»

Bakanlar Kurulu'nun 13.1.1960 tarih ve 4/12578 sayılı Kararı ile kabul edilen “**Tıbbî Deontoloji Nizamnamesi**”nde (RG: 19.2.1960/10436.) bu konuda şu hükümler yer almaktadır:

«Madde 2- *Tabip ve dış tabibinin başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyeti-
ne ihtimam ve hürmet göstermektir.*

*Tabip ve dış tabibi; hastanın cinsiyeti, ırkı, milliyeti, dini ve mezhebi, ahlâkî düşünceleri,
karakter ve şahsiyeti, içtimai seviyesi, mevkii ve siyasi kanaati ne olursa olsun, muayene ve
tedavi hususunda âzami dikkat ve ihtimamı göstermekle mükelleftir.*

Madde 3- *Tabip, vazifesi ve ihtisası ne olursa olsun, gerekli bakımın sağlanamadığı acil va-
kalar da, mücbir sebep olmadıkça, ilk yardımda bulunur.*

Dış tabibi de, kendi sahasında aynı mükellefiyete tabidir.

Madde 11- *Tecrübe maksadı ile insanlar üzerinde hiç bir cerrahi müdahale yapılamıyacağı gibi
aynı maksatla, kimyevî, fiziki veya biyolojik şekilde herhangi bir tedavi de tatbik edilemez.*

Klasik metodların bir hastaya fayda vermiyeceği klinik veya laboratuvar muayeneleri neticesinde sabit olduğu takdirde, daha önce, mütat tecrübe hayvanları üzerinde kâfi derecede denenmek suretiyle faydalı tesirleri anlaşılmış olan bir tedavi usulünün tatbiki caizdir. Şu kadar ki, bu tedavinin tatbik edilebilmesi için, hastaya faydalı olacağının ve muvaffakiyet elde edilmemesi halinde ise mütat tedavi usul-
lerinden daha elverişsiz bir netice alınmayacağının muhtemel bulunması şarttır.

*Evvelce tecrübe edilmiş olmamakla beraber, zarar vermesine ihtimal bulunmayan ve hastayı
kurtarması katî görülen bir müdahale yapılabilir.*

Madde 13- *Tabip ve diş tabibi, ilmi icapları uygun olarak teşhis koyar ve gereken tedaviyi tatbik eder. Bu faaliyetlerinin mutlak surette şifa ile neticelenmemesinden dolayı, deontoloji bakımından muaheze edilemez.*

Tababet prensip ve kaidelerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yasaktır.

Tabip ve diş tabibi; teşhis, tedavi veya korunmak gayesi olmaksızın, hastanın arzusuna uyararak veya diğer sebeplere, aklî veya bedenî mukavemetini azaltacak her hangi bir şey yapamaz.

Madde 14- *Tabip ve diş tabibi, hastanın vaziyetinin icabettirdiği sıhhi ihtimamı gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak ve sıhhatini korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmakla mükelleftir.*

Tabip ve diş tabibi hastasına ümit vererek teselli eder. Hastanın maneviyatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimali bulunmadığı takdirde, teşhise göre alınması gereken tedbirlerin hastaya açıkça söylenmesi lâzımdır. Ancak, hastalığın, vahim görülen akıbet ve seyrinin saklanması uygundur.

Meş'um bir prognostik hastanın kendisine çok büyük bir ihtiyatla ihsas edilebilir. Hasta tarafından, böyle bir prognostığın ailesine açıklanmaması istenilmemiş veya açıklanacağı şahıs tâyin olunmamış ise, durum ailesine bildirilir.»

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “**Hasta Hakları Yönetmeliği**”nde (RG: 1.8.1998/23420) şu hükümlere yer verilmiştir:

«İlkeler

Madde 5-

a) *Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima gözönünde bulundurulur.*

b) *Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.*

...

d) *Tıbbî zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.*

Hastanın Rızası ve İzin

Madde 24- *Tıbbî müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunmadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.*

Kanuni temsilci tarafından muvafakat verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbî müdahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanunu'nun 272'nci ve 431'inci maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.

Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması zaman gerektirecek ve hastaya derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisi tehdit altına girecek ise, izin şartı aranmaz.

Üçüncü fıkrada belirtilen ve hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil haller haricinde, rızanın her zaman geri alınması mümkündür. Rızanın geri alınması, hastanın tedaviyi reddetmesi anlamına gelir.

Rızanın müdahale başladıktan sonra geri alınması, ancak tıbbî yönden sakınca bulunmaması şartına bağlıdır.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

Madde 25- *Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir.*

Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanılamaz.

Küçüğün veya Mahcurun Tıbbî Müdahaleye İştiraki

Madde 26- *Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerektiği ve yeterli olduğu hallerde dahi, mümkün olduğu ölçüde küçük veya mahcur olan hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbî müdahaleye iştiraki sağlanır.*

Rızanın Şekli ve Geçerliliği

Madde 28- *Mevzuatın öngördüğü istisnalar dışında, rıza herhangi bir şekle bağlı değildir.*

Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür ve bu şekilde alınan rızaya dayanarak müdahalede bulunulamaz.

Rızanın Kapsamı

Madde 31- *Rıza alınırken hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbî müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması esastır.*

Hastanın, uygulanacak tıbbî müdahale için verdiği rıza, bu müdahalenin gerektirdiği sair tıbbî işlemleri de kapsar. Ancak, tıbbî işlemlerin uygulanmasında, bu Yönetmelik'te ve diğer mevzuatta belirlenen hakların ihlal edilmemesi için azami ihtimam gösterilir.

Yine, Türk Tabipler Birliği'nin 47. Genel Kurulunda 10-11 Ekim 1998 tarihinde kabul edilen "Hekimlik Meslek Etiği Kuralları"nda bu hususla ilgili olarak şu hükümlere yer verilmiştir:

«Hekimin Görev ve Ödevleri

Madde 5- *Hekimin öncelikli görevi, hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek hastaları iyileştirmeye çalışarak insanın yaşamını ve sağlığını korumaktır. Meslek uygulaması sırasında insan onurunu gözetmesi de, hekimin öncelikli ödevidir. Hekim, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, gelişmeleri yakından izler.*

Acil Yardım

Madde 10- *Hekim, görevi ve uzmanlığı ne olursa olsun, gerekli tıbbî girişimlerin yapılamadığı acil durumlarda, ilk yardımda bulunur.*

Meşru ve Yasak Yöntemler

Madde 12- *Hekim mesleğini yerine getirirken, bilimsel ve çağdaş tanı ve tedavi yöntemleriyle koruyucu hekimlik ilkelerini göz önünde bulundurur; hastalarının tanı ve tedavisinde bilimsel olmayan yöntemleri uygulayamaz. Hekim, gerekli bilimsel aşamalardan geçip ruhsatlandırılmamış kimyasal, farmakolojik, biyolojik maddeleri ilaç olarak kullanamaz.*

Yetkinlik Dışı Faaliyet Yasağı

Madde 18- *Hekim tıbbî görevlerini yerine getirirken, gecikmenin hasta yaşamını tehdit edebileceği zorunlu durumlar dışında özel bilgi, beceri gerektiren bir girişimde bulunamaz.*

Hasta Haklarına Saygı

Madde 21- *Hekim hastasının sağlığı ile ilgili kararlar alırken; bilgilenme hakkı, aydınlatılmış onam hakkı, tedaviyi kabul ya da red hakkı, vb. hasta haklarına saygı göstermek zorundadır.*

Aydınlatılmış Onam

Madde 26- *Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yönteminin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında aydınlatır. Yapılacak aydınlatma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gösteren bir uygunlukta olmalıdır. Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilir biçimde verilmelidir. Hastanın dışında bilgilendirilecek kişileri, hasta kendisi belirler. Sağlıkla ilgili her türlü girişim, kişinin özgür ve aydınlatılmış onamı ile yapılabilir. Alınan onam, baskı, tehdit, eksik aydınlatma ya da kandırma yoluyla alındıysa geçersizdir.*

Acil durumlar ile, hastanın reşit olmaması veya bilincinin kapalı olduğu ya da karar veremeyeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır. Hekim temsilcinin izin vermemesinin kötü niyete dayandığını düşünüyor ve bu durum hastanın yaşamını tehdit ediyorsa, durum adli mercilere bildirilerek izin alınmalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda, hekim başka bir meslektaşına danışmaya çalışır ya da yalnızca yaşamı kurtarmaya yönelik girişimlerde bulu-

rumlarda, gerçekleştirilen tıbbî müdahalenin hukuka uygunluğunu “*mefruz, var-sayılan rıza*”ya dayalı olarak açıklayan görüşlere⁵⁵⁹ iştirak etmemekteyiz. Varsayıma dayalı olarak hüküm tesis edilemez. Çünkü hukuk kurallarının dayanağını oluşturan davranış normları gerçeklik üzerine bina edilmişlerdir.

Tabibin görevi, sadece hasta olan bir insanın hastalığının teşhisi ve tedavisi amacına yönelik tıbbî müdahaleden ibaret değildir. Tabip, özel hukuk uyumsuzluğuyla ilgili bir davada ya da bir suç olayına ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinde, **bilir-kşi** olarak görevlendirilebilir. Tabibin bilirkişi olarak görevlendirildiği durumlarda bir **hasta - hekim ilişkisinin olmadığı** ve dolayısıyla, bu görev kapsamında gerçekleştirilecek tıbbî müdahalelerle ilgili olarak **kişinin rızasının aranmadığı**, göz önünde bulundurmamak gerekir. Örnek olarak, Ceza Muhakemesi Kanununun 74 ve devamı maddelerindeki düzenlemelerin bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir.

V. Teşhis ve tedavi amacına yönelik bir tıbbî müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için; ayrıca, bunun **tabiplik mesleğini icra etmek hususunda yetkiyle donatılan kişi**⁵⁶⁰ tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Uzmanlığı gerektiren bir tıbbî müdahale söz konusu ise; bunun, **uzmanı** olan **tabip** tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Uzmanlığı gerektiren ve fakat uzman tabip tarafından gerçekleştirilmeyen bir tıbbî müdahale, sonuçta kişi şifa bulmuş olsa bile, **hukuka uygun değildir**. Uzmanlığı gerektiren bir tıbbî müdahalenin uzmanı olmayan tabip tarafından gerçekleştirilmesi halinde, ancak **zorunluluk haline** ilişkin koşullar (TCK, m. 25, f. 2) bulunduğu takdirde, sorumluluk cihetine gidilemez⁵⁶¹.

İşaret etmek gerekir ki, kişi üzerinde gerçekleştirilecek her tıbbî müdahalenin münhasıran hekim tarafından yapılması gerekmemektedir. Bazı tıbbî müdahaleler, hekim dışında hemşire ve ebe gibi diğer sağlık görevlileri tarafından da gerçekleştirilebilirler⁵⁶².

nur. Acil durumlarda müdahale etmek hekimin takdirindedir. Tedavisi yasalarla zorunlu kılınan hastalıklar toplum sağlığını tehdit ettiği için hasta veya yasal temsilcisinin aydınlatılmış onamı alınmasa da gerekli tedavi yapılır.

Hasta vermiş olduğu aydınlatılmış onamı dilediği zaman geri alabilir.»

⁵⁵⁹ HAKERİ, Tıp Hukuku, sh. 165 vd., 287; ERMAN, Tıbbî Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, sh. 66, 77, 139 vd.

⁵⁶⁰ Ülkemizde tabiplik mesleğinin icrası için gerekli şartlarla ilgili olarak bkz. 11.4.1928 t. ve 1219 s. “*Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun*”. 1219 s. Kanunun bu husustaki düzenlemelerine ilişkin açıklamalar için bkz. ÇAKMUT, Özlem Yenerer: *Tıbbî Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi*, İstanbul 2003, sh. 26 vd.

⁵⁶¹ 1219 s. Kanunun 23. maddesi hükmü bu bağlamda göz önünde bulundurulmalıdır:

“*Umumi veya mevzii iptali his ile yapılan büyük ameliyeler behemehal ihtisas vesikasını hamil olan bir mütehassıs ile beraber diğer bir tabip tarafından yapılmak lazımdır. Mütehassıs bulunması veya celbi mümkün olmyan mahallerde yapılması zaruri görülen ameliyeler ile ahvali müstacele ve fevkalade bu hükümden müstesnadır.*”

⁵⁶² 1219 s. Kanunun, ebelerle ilişkin olarak 47 ila 57., sünnetçilere ilişkin olarak 58 ila 62., hemşirelere ilişkin olarak 63 ila 68. maddeleri hükümlerine bakılmalıdır.

VI. Keza, kişi üzerinde gerçekleştirilen tıbbî müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için, bunun **teşhis ve tedavi amacıyla** yapılması gerekir. Belirli bir hastalıktan korunmaya yönelik olarak aşı uygulaması halinde de **tedavi amacıyla** hareket edilmekte ve dolayısıyla, fiil hukuka uygun bulunmaktadır. Bir hastalığın teşhisi ve tedavisi amacı taşımayan bir tıbbî müdahale, hukuka uygun değildir.

Ancak, Kanun koyucu, belirli bir hastalığın teşhis ve tedavi amacını taşımasa bile, çeşitli mülahazalarla, kişiye tıbbî müdahalede bulunulmasına imkan tanımaktadır. Örneğin, **kan bağışı** ile ilgili olarak 11.4.2007 t. ve 5624 s. *Kan ve Kan Ürünleri Kanununda*, **kişilerden organ veya doku alınması** ile ilgili olarak 29.5.1979 t. ve 2238 s. “*Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda*, **kısırlaştırılma** ve **kürtajla** ilgili olarak 27.5.1983 t. ve 2827 s. *Nüfus Plânlaması Hakkında Kanunda*, **cinsiyet değişikliği** ile ilgili olarak 22.11.2001 t. ve 4721 s. *Türk Medeni Kanununun* 40. maddesinde, **bilimsel** bir **deney**le ilgili olarak, *Türk Ceza Kanununun* 90. maddesinde hükümler bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki, bu durumlarda söz konusu amaçlar doğrultusunda kişiye tıbbî müdahalede bulunulabilmesi için, rızasının varlığı gereklidir.

VII. Bir **tıbbî müdahalenin** hukuka uygun kabul edilebilmesi için, ayrıca **tıp biliminin verilerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir**⁵⁶³. Tıp biliminin verilerine uygun olmayan bir müdahale, tedavi amacıyla ve kişinin rızasıyla gerçekleştirilmiş olsa bile, hukuka uygun değildir.

Kişi üzerindeki tıbbî müdahalenin tıp biliminin verilerine uygun olup olmadığının tespitinde, **müdahalenin gerçekleştiği tarih itibarıyla tıp biliminin gelişmişlik düzeyi** göz önünde bulundurulmalıdır. Tıp bilimindeki gelişmeler karşısında, bir müdahale yönteminin bilahare sakıncalı ve hatta yanlış olduğu tespit edilmiş olabilir. Ancak bu tespit, gerçekleştirildiği tarihte tıp biliminin verilerine uygun olması itibarıyla, bir tıbbî müdahaleyi hukuka aykırı fiil olarak kabul etmemizi gerektirmez.

Hastalığın arzettiği özellikler ile hastanın içinde bulunduğu sağlık şartları göz önünde bulundurularak belirlenen bir tıbbî müdahale yönteminin hastanın sağlığı ve hatta hayatı bakımından belli oranda risk oluşturması ve hatta, bu risk oranının fazlalığı, bu tıbbî müdahalenin hukuka uygunluğunu etkilemez. Yapılan tıbbî müdahalenin teşhis ve tedavi amacına yönelik olması ve yapıldığı tarih itibarıyla tıp biliminin verilerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olması, hukuka uygunluk açısından yapılacak olan değerlendirmede başvurulacak olan ölçütlerdir. Hukuka uygunluk açısından önemli olan, hastanın tedavi edilmemesinin sağlığı ve hayatı bakımından oluşturduğu risk ile, belirlenen tıbbî müdahale yönteminin kişinin sağlığı ve hayatı bakımından oluşturduğu riskin mukayesesi sonucunda, ikincisi-

⁵⁶³ ÖZGENÇ, İzzet: *Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Genel Hükümler*, 3. bası, Ankara 2006, sh. 347 vd.; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 2. bası, sh. 176.; GÖKCAN, 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi, sh. 109.

nin birincisine tercih edilmesidir. Bu itibarla belirtmek gerekir ki, tıp biliminin verilerine uygun olarak gerçekleştirilen tıbbî müdahale, sonuçta kişi hayatını kaybetse bile, hukuka uygundur. Ancak, tıbbî müdahale ile bağlantılı olarak **riziko-nun artırılması yasağının** olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir⁵⁶⁴. Bu itibarla, tıbbî müdahalede bulunulması halinde gerçekleşmesi muhtemel olan sonuç, müdahalede bulunulmaması halinde gerçekleşmesi muhtemel olan sonuçtan daha ağır ise, tıbbî müdahaleden imtina edilmesi gerekir. Keza, sonuçları bakımından daha az riskli olan tıbbî müdahale yönteminin tercih edilmesi gerekir⁵⁶⁵.

Ekskurs 6. Sünnet Uygulamasının Hukuki Açından Değerlendirilmesi

Dini açıdan gerekli olup olmadığı bir yana, erkek çocukların sünnet ettirilmesine ilişkin uygulamanın hukuki bakımdan değerlendirmeye tabi tutulması gerekir.

Öncelikle belirtilmelidir ki, kişinin vücudu üzerinde mutlak bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Kişinin kendisine acı vermeye yönelik olarak vücuduna karşı bir fiil işleme hususunda bir başkasına rıza açıklamasında bulunmasının hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Ancak, kişiye acı verse bile, sağlığının gerekli kılması halinde, vücudu üzerinde belirli bir tasarrufta bulunulmasına yönelik olarak açıkladığı rıza, bu tasarrufu hukuka uygun hale getirmektedir.

Örneğin diş kökünde oluşmuş enfeksiyonun temizlenmesine yönelik olarak açıklanan rıza üzerine tıbbî müdahalenin gerekli kıldığı şartlar çerçevesinde vücut üzerinde bulunulan tasarruf, hukuka uygundur. Bu durumda vücut üzerinde belirli bir tasarrufta bulunmak kişinin sağlığı bakımından, tıbbî bakımdan gereklilik arz etmektedir. Bazı durumlarda gerekli olmadığı halde, kişinin sağlığı bakımından herhangi bir mahzur oluşturmayan belirli tıbbî müdahalelere hukuken izin verilebilmektedir. Estetik müdahaleler bunun örneğini oluşturmaktadır. Ancak, kişinin sağlığı bakımından mahzurlu olan müdahale, “tıbbî” mülahazalarla yapılmış olsa bile, hukuka uygun değildir. Örneğin, kişi üreme yeteneğinin ve hatta cinsel organlarının köreltilmesine yönelik bir tıbbî müdahaleye rıza göstermiş olsa bile, bu rızaya dayalı olarak vücut üzerinde bulunulan tasarruf, kasten yaralama suçunu oluşturur.

Erkek çocukların sünnet ettirilmesinin vücut sağlığı bakımından bir gereklilik oluşturmaya bile, tıbbî müdahale şartlarına uygun olarak icra edilmesi kaydıyla

⁵⁶⁴ HAKERİ, Tıp Hukuku, sh. 191.

⁵⁶⁵ Bir hastalığın tedavisi için **daha az riskli olan ilaç varken, risk oranı yüksek olan ilacın kullanılması hukuka aykırıdır**. Bu durumda, ekonomik kaygılar (örneğin Devlet bütçesine yüklenen yük), risk oranı yüksek olan ilacın kullanılmasına haklılık kazandırmaz. Devletin tazminat sorumluluğu bakımından Danıştay Onuncu Dairesinin 14.11.1996 tarihli ve 7534/7086 sayılı Kararı önem taşımaktadır. Ancak, daha az riskli ilacın varlığına rağmen, temini konusunda bir **imkansızlık** söz konusu olduğu için risk oranı yüksek olan ilacın kullanılması ve bu nedenle hastanın ölmesi halinde, kanımızca, TCK’nın **zorunluluk haline** ilişkin hükümleri (m. 25, f. 2) karşısında ceza sorumluluğu cihetine gidilemez.

kişinin sağlığı bakımından yararlı olduğu ve en azından bir mahzur oluşturmadığı muhakkaktır.

Tıbbi müdahale şartlarına uygun olarak icra edilmek üzere sünnet edilmeye yönelik olarak açıklanmış olan rıza, bu tıbbi müdahaleye yönelik olarak **hukuka uygunluk sebebi** oluşturur.⁵⁶⁶

Alman Medeni Kanununa 20.12.2012 tarihli Kanunla eklenen “*Beschneidung des männlichen Kindes*” (“Erkek çocuğun sünnet edilmesi”) başlıklı § 1631d hükümlerine göre, sünnet, erkek çocuğun vücut bütünlüğüne “*tıbbi bakımdan gerekli olmayan bir müdahale*”dir. Buna rağmen, velayet ilişkisine dayalı olarak, algılama ve karar verme yeteneği gelişmemiş olan erkek çocuğun sünnet edilmesi konusunda ebeveyne muvafakat etme hakkı tanınmıştır. Keza, bu muvafakate binaen çocuğun vücut bütünlüğüne bulunulacak olan müdahalenin tıp biliminin gereklerine uygun olması gerekir. Ancak, yapılış amacına uygun olsa bile, çocuğun beden ve özellikle ruh sağlığını tehlikeye maruz bırakacaksa, sünnete müsaade edilmez (f. 1). Fıkra metninde yer alan bu son cümle ile ifade edilen hükümden neyin anlaşılması gerektiği hususunda bir belirsizlik mevcuttur.

Keza, erkek çocuğun, doğumundan itibaren altı ay içinde, ebeveynin muvafakatine istinaden, tabip olmasa bile, sünnet ameliyesini tıp biliminin gereklerine uygun bir şekilde icra edebilen ve Musevi toplumunun yetkili kıldığı bir kişi tarafından sünnet edilmesi, hukuka uygun sayılmıştır (§ 1631d, f. 2).

Bu madde hükmünde söz konusu edilen ebeveynin muvafakatinden, **her iki eşin, anne ve babanın müşterek rızasını** anlamak gerekir.⁵⁶⁷

Söz konusu kanuni düzenleme yapılcaya kadar, Alman hukuk uygulamasında; örneğin dört yaşındaki erkek çocukla ilgili sünnetin, anne ve babasının müşterek muvafakatine istinaden ve tabip tarafından tıp biliminin gereklerine uygun olarak yapılmış olsa bile, kasten yaralama suçunu (Alman CK, § 223) oluşturduğu kabul edilmekteydi.⁵⁶⁸ Ebeveynin muvafakati, bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmemekteydi. Zira bu kabule göre, sünnet, çocuk haklarıyla bağdaşmamakta ve çocuğun beden bütünlüğüne fiziki ve özellikle ruh sağlığına bir katkı sağlamayan bir müdahale mahiyeti taşımaktadır.

Ancak, söz konusu §1631d düzenlemesi öncesinde, ebeveynin muvafakatine istinaden çocuğu sünnet eden tabibin kaçınılmaz bir haksızlık yanılığı içinde olduğu ve işlediği bu suç sebebiyle kusurunun bulunmadığı kabul edilmekteydi.⁵⁶⁹

⁵⁶⁶ Akbulut, erkek çocukların sünnetini “fiilin sosyal uygunluğu” ile izah etmekte, buna karşılık kız çocuklarının sünnetini ise, kasten yaralama suçu olarak değerlendirmektedir: AKBULUT, Genel Hükümler 5. bası, sh. 225.

⁵⁶⁷ BVerfG 1. Senat 1. Kammer, 13.02.2013, 1 BvQ 2/13.

⁵⁶⁸ LG Köln, Urteil vom 7.5.2012, Az: 151 Ns 169/11 (NJW 2012, 2128).

⁵⁶⁹ OLG München, Beschluss vom 26.7.2016, Az: 1 W 1101/16; LG München I, Beschluss vom 23.6.2016, Az: 9 O 2436/16.

Türk hukuku uygulamasında sünnetle ilgili olarak bir meşruiyet tartışması bulunmamaktadır. 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı “*Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun*”un 3. maddesinde 2.1.2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunla (m. 20) yapılan değişiklikle, sünnet uygulamasını “*her tabip yapabilir*” hükmüne yer verilmiştir (f. 1, ikinci cümle). Keza, söz konusu değişiklikle, fıkra yeni bir cümle eklenmiştir. Buna göre, “*olağanüstü ve istisnai hâllerde Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan kimseler tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir*”. Dikkat edilmelidir ki, bu değişiklikle sadece sünnet uygulamasını yapmaya yetki bağlamında bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin esasını, henüz reşit olmayan çocuğun sünnet edilmesiyle ilgili olarak ebeveynin açıkladığı **rızanın**, bu tıbbi müdahale bağlamında bir **hukuka uygunluk sebebi** oluşturduğu yönündeki kabul oluşturmaktadır. Bu rıza, velayet yetkisi kapsamında açıklandığı için, bir hukuka uygunluk sebebi oluşturmaktadır. Sünnet uygulamasının hukuka uygun kabul edilebilmesi için, henüz reşit olmamış çocuğun anne ve babasının her ikisinin müştereken açıklayacağı rızaya istinaden ve tıp biliminin gereklerine uygun olarak icra edilmesi gerekir. Madde metninde aleliltlak “sünnet” ibaresine yer verilmiştir. Bu düzenlemenin erkeklere münhasır mı olduğu yoksa kadınların sünnetini de mi kapsadığı konusunda Kanunda bir açıklık bulunmamaktadır.

IV. Kabahatlerde Hukuka Aykırılık Unsuru ve Kabahatlerle İlgili Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması

5326 s. Kabahatler Kanununun 12. maddesi hükmü gereğince, Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenleri, kabahatler bakımından da uygulanacaktır.

Hukuka uygunluk sebeplerinin kapsamını belirleme bakımından madde **gereğince** ayrıca şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin hükümleri, hakkın kullanılması, görevin yerine getirilmesi, meşru savunma ve ilgilinin rızası olmak üzere dört ana grupta toplanabilir.”

§17. İhmalî Suçlar

I. İhmal, davranış normlarıyla ve dolayısıyla, hukuk kurallarıyla kişiye **belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğü**nün tahmil edildiği hallerde, kişinin bu yükümlülüğü yerine getirmemesidir. Bu nedenledir ki; insan davranışının ontik vasıfları itibarıyla; bir başka ifadeyle, davranışın oluşum şekli itibarıyla; icraî davranışla ihmalî davranış arasında bir müştereklik sözkonusu değildir⁵⁷⁰. Bu iki davranış tarzı arasındaki müştereklik, normatif sahada, yani bu icraî veya ihmalî davranışın, hukuk kurallarından kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırılık ve dolayısıyla, bir haksızlık teşkil ettiği hususunda mevcuttur⁵⁷¹.

İhmalî davranış, kaynağını davranış normlarından ve dolayısıyla, hukuk kurallarından alan **belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğü**nün yerine getirilmemesi olarak tezahür etmektedir. Davranış normunun ve ilgili hukuk kuralının korumayı hedeflediği hukuki değer, bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi suretiyle, ihlâl edilmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi, yani ihmalî; belli bir hukuki değer in ihlâli mahiyetini taşıyacak ve dolayısıyla, bir haksızlık teşkil edecektir.

Hukuk toplumunda yaşayan her fert, can ve mal güvenliği içinde yaşama hakkına sahiptir. İnsanın sahip olduğu yaşama hakkı, soyut bir hak olmayıp, *güvenlik içinde bir yaşama hakkı*dır. Bir başka ifadeyle; insan, içinde bulunduğu toplumda hayatına, vücudunun ve konutunun (meskeninin) mahremiyetine (dokunulmazlığına) ve sahip olduğu sair değerlere her türlü tecavüzden emin olarak yaşamalıdır.

Keza, insan *sağlıklı bir hayat sürme hakkını* haizdir. Adil toplum düzeninde yaşayan insan, herhangi bir sebeple sağlık şartları bozulmuş olması halinde, kendisine sağlığını iyileştirici tıbbî müdahalede bulunulacağından emin olmalıdır.

Bu genel düşünceler ışığında bazı örnekler vererek meseleyi izaha çalışalım:

1) Bir yangın felâketi sırasında can ve mal güvenliği tehlikeye maruz kalmış olan kişileri bu tehlikeden korumak, itfaiye teşkilatı personeline terettüp eden bir görevdir. Bu itibarla, bir yangında yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kişiyi bu tehlikeden kurtarmakla yükümlü olan itfaiye görevlisi, bu yükümlülüğü yerine getirmemekle, bir haksız tutum içine girmektedir.

2) İnsanların can ve mal güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almakla yükümlü emniyet görevlileri, bu görevlerini yerine getirmemeleri halinde, haksız bir tutum içinde olacaklardır. Buna göre, bir suç vakasıyla karşılaşan emniyet görev-

⁵⁷⁰ Kunter, ihmalî davranışın da, icraî davranış gibi, “maddi bir varlığı olduğu kanaatinde”dir (KUNTER, Suçun Maddi Unsurları, sh. 34).

⁵⁷¹ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 159 vd.; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 60 vd. Farklı bir değerlendirme için bkz. YURTLU, Fatih, *İhmalî Suçlar*, henüz yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kasım 2020, sh. 76 vd., 172 vd.

lileri, suç işleyen kişilerin bu fiilini engellemek için olaya *müdahale yükümlülüğü* altındadır (önleyici kolluk). Yine, bir hırsızlık suçunun işleneceği hususunda bir planın varlığından haberdar olan bekçi, bu suçun işlenmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

3) Bir suçun işlendiğinden haberdar olan kişi, bu hususu ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür. Hukuk toplumunda kişiler, devletten suçluların cezalandırılmasını talep etme hakkına sahiptirler. Böylece, işlenen suç vakiasını yetkili makamlara *ihbar*; Hukuk Devletinde yaşayan, Hukuk Devletinde yaşama hakkını haiz fert bakımından bir *selâhiyet*, bir *yeti*, bir *yetki*, kısaca bir *hak* olmanın yanı sıra; toplumu oluşturan diğer fertlere karşı bir *görevdir*, bir *vazifedir*.

4) Keza, kişi bir hukuki ihtilafın mesnedini teşkil eden müşahhas vakıa hakkında beş duyusuyla sahip olduğu bilgiyi, bu hukuki ihtilafı halletmekle görevli yargı mercii önünde -doğru olarak- aktarmakla yükümlüdür. Bir maddi vakıayı aydınlığa kavuşturacak bilgiye sahip kişinin bu görevini yerine getirmemesi, bir haksızlık teşkil eder.

5) Bir kamu hizmeti sunan bir sağlık kurumu personeli; herhangi bir sebeple sağlık şartları bozulmuş olan bir kimseye iyileştirici tıbbî müdahalede bulunmakla görevlidir. Bir kaza sonucu yaralanan kişiye tıbbî müdahale yükümlülüğü altında bulunan tabip, bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, bir haksızlık gerçekleştirmektedir.

6) Belli tehlike kaynaklarının sebebiyet verebileceği zararları önleme yükümlülüğü altında bulunan kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, bir haksızlık teşkil edecektir. Meselâ, hayvan besleyen şahıs, beslediği hayvanın başkasına bir zarar vermemesi hususunda bir yükümlülük altındadır.

7) İnsan, belli hukuki değerlerle alakalı olarak belli davranışlarda bulunma yükümlülüğü altındadır.

Meselâ, aileyi oluşturan bir unsur (ana veya baba) olarak insan, dünyaya getirdiği çocuğa karşı velayet ilişkisinden kaynaklanan belli yükümlülükler altındadır (Bkz. 22.11.2001 t. ve 4721 s. Türk Medeni Kanunu, m. 335 vd.). Ana veya baba olarak insanın bu yükümlülükleri yerine getirmemesi, bir haksızlıktır.

Aynı şekilde, belli bir miktar malvarlığına sahip kişilere tahmil edilen, vergi vermek gibi, mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, bir haksızlık teşkil eder.

Davranış normlarından kaynaklanan bu *icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün* salt yerine getirilmemesi, bir haksızlık teşkil eder. Bu haksızlıklardan önemli bir kısmı, TCK'da suç olarak tanımlanmıştır. Örneğin, kişinin,

- yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye yardım etmemesi ya da durumu derhâl ilgili makamlara bildirmemesi (m. 98, f. 1),

- kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşyayı iade etmemesi veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmemesi (m. 160),
- bir hukuki ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suç takibe yetkili mercilere vakit geçirmeksizin bildirimde bulunmaması (m. 166),
- akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal etmesi (m. 175),
- inşaat veya yıkım faaliyeti sırasında gerekli olan tedbirleri almaması (m. 176),
- gözetimi altında bulunan hayvanı kontrol altına almada ihmal göstermesi (m. 177),
- herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymaması (m. 178),
- işlenmekte olan veya işlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmemesi (m. 278, f. 1, 2),
- kaçak olan tutuklu veya hükümlüyü bildirmemesi (m. 284, f. 1),
- bir suça ait delillerin saklandığı yeri bildirmemesi (m. 284, f. 2).

Keza, kamu görevlisinin,

- kişinin hatasından yararlanarak, kendisine veya başkasına yarar sağlaması (m. 250, f. 3),
- denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine imkan sağlaması (m. 251, f. 2),
- görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olması ya da kişilere haksız bir menfaat sağlaması (m. 257, f. 2),
- kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de, yetkili mercilere bildirimde bulunmayı ihmal etmesi veya bu hususta gecikme göstermesi (m. 279, f. 1),
- sulh zamanında seferberlikle ilgili görevlerini ihmal etmesi veya geciktirmesi (m. 324),

bir yükümlülüğün salt yerine getirilmemesi olarak, suç teşkil etmektedir.

Bu örneklerde suçun oluşması için kişinin icraî davranışta bulunma yükümlülüğünü kasten yerine getirmemiş olması yeterlidir. Bu ihmalî davranışın sonucunda bir insanın ölmesi gibi ayrıca herhangi bir neticenin meydana gelmesi, suçun oluşması için zorunlu değildir.

Kanunda *serbest hareketli suç* olarak tanımlanmış olan suçlar, icraî davranışla işlenebileceği gibi, ihmalî davranışla da işlenebilir. Taksirle ölüme sebebiyet verme (m. 85), taksirle yaralamaya sebebiyet verme (m. 89), terk (m. 97, f. 1), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (m. 109, f. 1), konut dokunulmazlığının ihlâli (m. 116, f. 1) ve zimmet (m. 247), bu suçlara örnek olarak gösterilebilir.

Çok hareketli suç niteliği taşıyan dolandırıcılıkta, suçu oluşturan icra hareketlerinden *hile*, icraî davranışla gerçekleştirilebileceği gibi, ihmalî davranışla da gerçekleştirilebilir (m. 157).

Belli bir yönde icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sonucunda, örneğin bir insan yaralanmış, sağlığı bozulmuş ve hatta ölmüş olabilir; bir başkasının malına zarar verilmiş olabilir.

Sözünü ettiğimiz bu neticelerin meydana gelmesi halinde, başlı başına bir haksızlık teşkil eden ihmalî davranışın niteliğinde bir değişiklik meydana gelmemektedir.

Örneğin, bir yangın felaketinin vukuunda bu yangına müdahale edip kontrol altına almakla yükümlü olan itfaiye görevlileri, müdahale etme imkanına sahip olmalarına rağmen, kasten yangına müdahale etmezler. Bu durumda iki ihtimalle karşılaşabiliriz:

Birinci ihtimal: İtfaiye görevlilerinin yükümlülüklerini kasten yerine getirmemelerine rağmen; sair şahısların yangına müdahale etmesi sonucu veya başka bir sebeple, yangında meselâ can kaybı önlenmiş olur. Bu durumda bir can kaybı meydana gelmez. Ancak, vuku bulan yangına müdahale etmekle yükümlü olan görevliler, bu yükümlülüklerini kasten yerine getirmezler.

İkinci ihtimal: İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale yükümlülüklerini kasten yerine getirmemeleri neticesinde; çıkan yangında can kaybı meydana gelir.

Dikkat edilirse, itfaiye görevlileri, yangına müdahale edip kontrol altına alma hususundaki yükümlülüklerini bu iki ihtimalde de kasten yerine getirmezler. Dolayısıyla; ihmalî davranışta bulunma bakımından, bu ihmalî davranışta bulunurken fail(ler)in içinde bulunduğu manevi durum bakımından her iki ihtimal arasında bir farklılık mevcut değildir. Bir başka ifadeyle; her iki ihtimalde de ihmalî davranışın gerçekleştirilişi bakımından bir *nitelik farkı mevcut değildir*.

Bu iki ihtimal arasındaki fark, gerçekleşen *netice bakımındandır*. Birinci ihtimalde can kaybı olmamış; ikinci ihtimalde ise, insan ölmüştür. Fakat bu netice farklılığı, ihmalî davranışın hukuki niteliğinde bir değişikliği gerekli kılmaz.

Ancak, Kanun koyucu, belli yönde icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi neticesinde bir insan ölmüş veya yaralanmış olması hallerine ilişkin olarak Kanunda ayrı hüküm vaz'etmek suretiyle, esasen icraî davranışla işlenen bu suçların ihmalî davranışla da işlenebileceğini kabul etmektedir (m. 83, 88).

Teminat yükümlülüğü (garantörlük)⁵⁷² olarak ifade ettiğimiz, kişinin koruma ve gözetim yükümlülüğünü, belirli bir konuya yönelik tehlikenin önlenmesi yükümlülüğünü kasten yerine getirmemesi sonucunda oluşan neticeden dolayı ceza hukuku bakımından sorumlu tutulduğu durumlarda **görünüşte ihmalî suç** söz konusu olmaktadır. Buna karşılık, belli bir yönde icraî davranışta bulunma yükümlülüğüne rağmen, kişinin ortaya çıkabilecek veya çıkan neticeyi önleme hususunda teminat yükümlülüğünün bulunmadığı veya herhangi bir neticenin gerçekleşmesine gerek bulunmayan durumlarda ise, **gerçek ihmalî suç** söz konusudur.

Görünüşte ihmalî suç, esasen icraî bir davranışla işlenebilen suçtur. Ancak, kişi belli bir neticenin gerçekleşmesini önlemek hususunda özel bir yükümlülük altında bulunduğu için, bu neticenin oluşumuna kendisi neden olmasa bile, bunun oluşumunu engellememiş olması halinde, ihmalî davranışla bir suç işlemiş kabul edilmektedir. Meselâ, bir itfaiye görevlisi çıkan yangını söndürmek hususundaki yükümlülüğünü yerine getirmez ve binada bulunan bir yaşlı kişi bu nedenle ölürse, kasten öldürme suçunu ihmalî davranışla işlemiş olur. Keza, acil tıbbî müdahaleye ihtiyaç duyan bir hastaya görevli tabip tarafından gerekli tıbbî müdahalede bulunulmaz ve netice olarak hasta ölürse, ihmalî davranışla işlenmiş olan bir kasten öldürme suçu söz konusudur.

Ceza kanununun özel kısmındaki suç tanımları, hırsızlık konusu eşyayı almak, bir insanı öldürmek veya yaralamak gibi kural olarak ancak icraî davranışla işlenebilir. Bu suçların belli şartların gerçekleşmesine bağlı olarak ihmalî davranışla da işlenebileceğinin kabulü için, suçta kanunilik ilkesinin gereği olarak, kanunî düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu bağlamda bazı ülke ceza kanunlarında genel hükümler kısmında genel bir düzenleme yapılarak sorun çözülmeye çalışılmıştır.⁵⁷³ Bu şekilde düzenleme yapılan kanunların uygulanmasında, örneğin kasten öldürme ve kasten yaralama suçları bakımından sorun çözülmüş görünmektedir. Ancak, bu kanunlar bakımından özel hükümler kısmında tanımlanan ve icraî davranışla işlenebilen hangi suçların ihmalî davranışla da işlenebileceğinin kabulünde yine de sorunla karşılaşmıştır.

Bu tartışmalı durumun önüne geçmek için, yeni TCK'nın "Genel Hükümler" başlıklı Birinci Kitabında ihmalî suçlarla ilgili genel bir düzenleme yapılması yoluna gidilmemiş; çeşitli özel suçlar bağlamında suçun ihmalî davranışla iş-

⁵⁷² Kavramla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. YURTLU, Doktora Tezi, sh. 184, dn. 651; sh. 197, dn. 694.

⁵⁷³ Almanya CK, "Begehen durch Unterlassen" ("ihmal suretiyle icra") başlıklı § 13.

İsviçre CK, "Begehen durch Unterlassen" ("ihmal suretiyle icra") başlıklı m. 11.

Avusturya CK, CK, "Begehung durch Unterlassung" ("ihmal suretiyle icra") başlıklı § 2.

lenmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. TCK bakımından benimsenen bu sisteme de doktrinde eleştiri yöneltilmiştir.⁵⁷⁴ Kanunî tanımında ihmalî davranışla da işlenebileceğine dair hüküm bulunmayan suçlar bakımından sorun olabileceği eleştirisinde bulunulmuştur. Ancak belirtmek gerekir ki, doktrindeki bu tartışmaya rağmen, uygulamada bu bağlamda henüz somut bir sorunla karşılaşmamıştır.

Görünüşte ihmalin cezalandırılabilirliği açısından en önemli sorun; sadece **neticeyi önleme yükümlülüğü altında bulunan kişinin (teminat yükümlüsünün, garantörün)** fail olabileceğinin hukuki izahıdır. Görünüşte ihmalî suçtan dolayı failin cezalandırılabilmesi için, neticeyi önlemek hususunda soyut bir ahlaki yükümlülüğün varlığı yeterli değildir. Neticenin önlenmesi hususunda **hukukî bir yükümlülüğün varlığı** gereklidir.

Neticeyi önleme yükümlülüğünün açıklanması hususunda genellikle “*koruma yükümlülüğü*”⁵⁷⁵ veya “*gözetim yükümlülüğü*”⁵⁷⁶ kavramları kullanılmaktadır. Biz, **teminat yükümlülüğü** kavramını kullanmayı tercih etmekteyiz.

Teminat yükümlülüğünün kaynaklarından biri, **kanundur**. Meselâ, velâyet ilişkisi, velâyet altında bulunan kişilerin davranışları açısından bir koruma veya gözetim yükümlülüğü oluşturmaktadır.

Teminat yükümlülüğü, bakım ve gözetimin iradî biçimde üstlenilmesi ile de oluşabilir. Bir başka ifadeyle, teminat yükümlülüğü bir **sözleşme ilişkisinden** kaynaklanabilir.

Teminat yükümlülüğünün bir diğer kaynağını, **ön gelen** (takaddüm eden) tehlikeli **fiil** oluşturmaktadır. Örneğin, trafik kazasında bir başkasının yaralanmasına neden olan kimse, yaralanan kişinin tedavi ettirilmesine, sağlığının iyileştirilmesine yönelik teminat yükümlülüğü altına girmektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda kişinin ölmesi halinde, kazaya neden olan ve yaralanan kişi ile ilgili olarak yardım ve bildirimde bulunmayan kimseyi kasten öldürme suçunu ihmalî davranışla işlemek dolayısıyla sorumlu tutmak gerektirir.^{577 578}

⁵⁷⁴ Bkz. YURTLU, Doktora Tezi, sh. 273, 278, 283.

⁵⁷⁵ "Beschützergarant". Bu durumda belli bir hukuki menfaatin bütün tehlikelere karşı savunulması söz konusudur (ayrıntılı bilgi için bkz. KAUFMANN, Armin: *Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte*, Göttingen, 1959, 283; BRAMMSEN, Joerg: *Die Entstehungsvoraussetzungen der Garantienpflichten*, Berlin, 1986, 149 vd.).

⁵⁷⁶ "Überwachungsgarant". Bu durumda ise, belirli tehlike kaynaklarının gözetim altında bulundurulması söz konusudur. Tehlikenin yöneltildiği hukuki menfaatin bizzat kendisi bir rol oynamamaktadır (KAUFMANN, Unterlassungsdelikte, 283; BRAMMSEN, 224 vd.; HERZBERG, Rolf Dietrich: *Täterschaft und Teilnahme*, München, 1977, sh. 96 dn.48).

⁵⁷⁷ A, alkollü olarak Devlet karayolunda geceleyin otomobiliyle seyrederken, azami hız sınırını aşarak, aracın kontrolünü kaybeder ve karşı istikametten bisikletiyle gelmekte olan B'ye çarpar.

II. Gerçek ihmalî suçlarla görünüşte ihmalî suçlar arasındaki fark bakımından belirleyici ölçüt, uyarıda da belirttiğimiz gibi, teminat yükümlülüğüdür. Teminat yükümlülüğü, failin hukuki statüsünden veya fail ile mağdur arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanmaktadır. Teminat yükümlülüğü, kural olarak, somut tehlike ortaya çıkmadan önce mevcuttur. Teminat yükümlülüğü, bu yükümlülüğe aykırı olarak gerçekleştirilen ihmalî davranışı icraî davranışla eşdeğer kılmaktadır.⁵⁷⁹

Örneğin anne ve baba, çocukla aralarındaki velayet ilişkisi dolayısıyla, çocuğa karşı teminat yükümlülüğü altındadır (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, m. 335 vd.). Velayet ilişkisinin gerekli kıldığı bakım ve gözetim yükümlülüğünün⁵⁸⁰ kasten yerine getirilmemiş olmasına bağlı olarak çocuğun yaralanması, hastalanması veya ölmesi durumunda, TCK, m. 83 ve 88 hükümlerine istinaden, anne ve babayı kasten öldürme veya kasten yaralama suçundan dolayı fail olarak sorumlu tutmaktayız.^{581 582}

B'nin ağır yaralandığını fark eden A, korkar ve olayı kimsenin görmemesinden yararlanarak, otomobiliyle olay yerinden kaçar. Sabahleyin yoldan geçenler, B'nin cesediyle karşılaşılır.

Bu olayda A, B'nin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermiş ve bu suretle TCK'nın 89. maddesinde tanımlanan taksirle yaralama suçunu işlemiştir. Ancak, A'nın durumu fark etmesine rağmen, hastaneye kaldırılması ve tedavi görmesi için gerekli yardımı yapmayı ihmal etmesi sonucunda B olay yerinde ölmüştür. Bu durumda A ayrıca kasten öldürme suçunu ihmalî davranışla işlemiştir ve bu sebeple TCK'nın 83. maddesi hükümleri çerçevesinde cezalandırılması gerekir. A, her ne kadar ayrıca taksirle yaralama suçunu işlemiş ise de, bu suç sebebiyle soruşturma ve kovuşturma yapılması şikayete bağlı olduğu (m. 89, f. 5) ve mağdur B şikayet hakkını kullanmadan öldüğü için, taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan dolayı cezalandırılmayacaktır.

⁵⁷⁸ Keza, B'ye bir silâh satan A, bilahare bu silâhla B'nin bir başkasına karşı öldürme fiili işleyeceğini öğrenirse, B'ye engel olmak yükümlülüğü altına girer. Ön gelen tehlikeli fiili işleyen kişinin neticeyi önleme yükümlülüğü mevcuttur: ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 151.

⁵⁷⁹ Bkz. Yargıtay CGK, 5.7.2013, E. 2012/2-796, K. 2013/339; KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan: *Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, 13. bası, Ankara, Eylül 2020, sh. 398, 399, 411.

⁵⁸⁰ 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, m. 335 vd.

⁵⁸¹ Kasten öldürme suçunun ihmalî davranışla işlenmesine ilişkin TCK, m. 83 hükmü, ayrı bir suç tanımı değil; kasten öldürme suçuna ilişkin 81 ve 82. maddeler hükümleriyle bağlantılı bir düzenlemedir. Bu itibarla, bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihmaline bağlı olarak çocuğun ölmesi halinde, bu yükümlülüğü kasten ihmal eden anne veya babayı cezalandırırken, kasten öldürme suçunun nitelikli unsurlarını düzenleyen TCK, m. 82 hükümlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenledir ki, TCK, m. 83, f. 3'de "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ve ayrıca "müebbet hapis cezası" ibarelerine yer verilmiştir. Bu itibarla, Koca/Üzülmüş'in, ceza belirlenirken suçun örneğin çocuğa karşı işlenmesi halinde de kasten öldürme suçunun temel şeklinin göz önünde bulundurulması gerektiği yönündeki görüşü (KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan: *Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler*, 7. bası, Ankara, Ekim 2020, sh. 146; aynı yazarlar, Genel Hükümler, 13. bası, sh. 409, dn. 1247), sorunludur (Bu konuda bkz. TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, Murat: *Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku*, 18. bası, Ankara, Eylül 2020, sh. 145).

⁵⁸² Aynı şekilde Yargıtay, yatalak hasta olması itibarıyla bakmakla yükümlü olduğu ve aynı konutta birlikte kaldığı yaşlı annesinin düşüp yaralanmasına rağmen, gerekli tıbbi tedavinin ya-

Anne ve babanın velayet ilişkisinden kaynaklanan bakım ve gözetim yükümlülüğü, sair bir kişinin çocuğa karşı işlemekte olduğu suçtan sorumluluk bakımından da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, çocuğun sair bir kişi tarafından cinsel istismara maruz bırakılmakta olduğuna muttali olan anne ve baba, bakım ve gözetim yükümlülüğünün gereği olarak, bu suçun işlenmesini önlemekle, önlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenledir ki, anne veya baba, çocuğun sair bir kişi tarafından cinsel yönden istismar edilmekte olduğuna muttali olmasına rağmen, fiilin işlenmesine herhangi bir icraî katkıda bulunmasa bile, işlenen bu cinsel istismar suçundan dolayı sorumlu tutulur. Bu durumda anne veya baba, **bir başkası tarafından işlenmekte olan çocuğun cinsel istismarı suçunun işlenişine ihmalî davranışla iştirak** etmiştir. Çocuğun cinsel istismarı suçunun ihmalî davranışla da işlenebileceğine dair Kanunda açık bir hüküm bulunmadığı için, teminat yükümlülüğü altında bulunan anne ve babayı, bu suçu ihmalî davranışla işlemekten dolayı fail sıfatıyla değil, **bir başkasının işlediği icraî suça ihmalî davranışla iştirak** etmekten dolayı, yani cinsel istismar suçunun **yardım edeni** sıfatıyla sorumlu tutmak gerekir.⁵⁸³

Evlilik birliğinde eşlerin de birbirlerine karşı teminat yükümlüsü olduğunu kabul etmek gerekir (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, m. 185, f. 3).

Keza, örneğin kolluk görevlisi, önleyici kolluk görevinin gereği olarak, suç işlenmesini önlemekle yükümlüdür (2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, m. 1); işlenişine, işlenmekte olduğuna muttali olmasına rağmen, bu yükümlülüğünün gereğini yerine getirmemesi halinde, işlenen suçtan dolayı sorumlu tutulur. Bu durumda kolluk görevlisini fail olarak mı yoksa şerik (yardım eden) sıfatıyla mı sorumlu tutmak gerektiğini, işlenen suçun kanuni tanımına bakarak belirlemek gerekir.

Şöyle ki, esasen icraî davranışla işlenebilen suça ilişkin kanuni tanımda suçun ihmalî davranışla işlenmesi de yaptırım altına alınmış ise, teminat yükümlülüğünün gereğini kasten yerine getirmeyen kolluk görevlisini ihmalî davranışla işlediği suçtan dolayı **fail** sıfatıyla sorumlu tutulacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama ve işkence suçları, bu bağlamda örnek olarak zikredilebilir. Bu durumda kolluk görevlisi bir başkası tarafından icraî davranışla işlenmekte olan bu suçun işlenişine ihmalî davranışla iştirak etmiş ise de, **failliğin şerikliğe nazaran aslîliği kuralı** gereğince, ihmalî davranışla işlediği örneğin kasten öldürme, kasten yaralama veya işkence suçundan dolayı **fail** sıfatıyla sorumlu tutulacak-

pılmasını sağlama hususunda hiçbir girişimde bulunmayan oğlunun, düşme olayının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bu yaralanmanın etkisiyle ölen annesinin ölümünden TCK, m. 83 hükümlerine göre sorumlu tutulması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur: Yargıtay 1.CD, **14.6.2012**, E. 4900, K. 2012/4943.

⁵⁸³ ÖZGENÇ, İzzet: *İcraî Suça İhmalî Davranışla İştirak, Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler*, in: Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Cilt 2, Sayı 1-2, Yıl 2014, sh. 1 vd.

tır.⁵⁸⁴ Dikkat edilmelidir ki, bu gibi durumlarda, icraî davranışla suçu işleyen kişi ile işlenmekte olan suçu önleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu görevlisi arasında suç işleme yönünde verilmiş ortak bir karar bulunması gerekmektedir.

Buna karşılık, başkası tarafından işlenmekte olduğuna muttali olmasına rağmen kolluk görevlisinin işlenmesini önlemeyi kasten ihmal ettiği suça ilişkin kanuni tanımında suçun ihmalî davranışla işlenmesi yaptırım altına alınmamış ise, kolluk görevlisi, bir başkası tarafından icraî davranışla işlenmekte olan bu suçun işlenişine ihmalî davranışla iştirak etmekte ve bu durum, işlenen suçtan **şerik (yardım eden)** olarak sorumluluğunu gerektirmektedir. Hırsızlık ve yağma suçları, bu bağlamda örnek olarak zikredilebilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, teminat yükümlülüğü, bir sözleşmeden de kaynaklanabilir. Bir çocuğun, yaşlı bir insanın bakım ve gözetimini üstlenen kişi, bu üstlenmeye bağlı olarak teminat yükümlülüğü altına girmektedir ve garantörlük sıfatını iktisap etmektedir.

Ayrıca, **ön gelen** bir **fiil** de teminat yükümlülüğünün kaynağını oluşturabilir. Taksirli davranışıyla bir başkasının yaralanmasına sebebiyet veren kişi, yaralanana karşı teminat yükümlülüğü altına girmektedir ve garantörlük sıfatını iktisap etmektedir.⁵⁸⁵

Yaygın görünüş biçimi olarak, karayolu trafik düzenine ilişkin kurallara aykırı araç kullanarak karıştığı trafik kazasında bir başkasının yaralanmasına sebebiyet veren sürücü, yaralanan kişinin tedavi edilmesini sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Teminat yükümlülüğünün kaynağını oluşturabilmesi için, ön gelen fiilin bir başkasının hayatı bakımından somut bir tehlike oluşturmaması gerekir.^{586,587,588,589}

⁵⁸⁴ KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan: *Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler*, 7. bası, Ankara, Ekim 2020, sh. 149. Ayrıca bkz. YURTLU, Doktora Tezi, sh. 206, dn. 724.

⁵⁸⁵ ÖZGENÇ, İzzet: *Suçta İştirakin Hukuki Esası ve Faillik*, İstanbul, 1996, sh. 151.

⁵⁸⁶ Yargıtay 4. CD, **25.12.2015**, E. 2014/34362, K. 2015/40853.

⁵⁸⁷ Aynı şekilde, insan sağlığı bakımından tehlikeli olduğu piyasaya sürüldükten sonra, bilahare tespit edilen ilaç veya gıdayı piyasaya sürenler, bu ilaç veya gıdayı kullanabilecek durumda olan kişilere karşı teminat yükümlülüğü altına girmektedirler (KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan: *Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, 13. bası, Ankara, Eylül 2020, sh. 409).

⁵⁸⁸ Yargıtay 12. Ceza Dairesinin **21.12.2017** tarihli ve E. 2016/3435, K. 2017/10707 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, sürücü belgesi bulunmayan S, sevk ve idaresindeki araçla, akşam saat 20.30-21.00 sıralarında aydınlatmanın bulunmadığı, bir bölümünde yol genişletme çalışması olması sebebiyle iki yönlü işleyen, çıkış eğimli, meskun mahal dışı ve hız sınırı 50 km olan Devlet yolunda seyir halinde iken, aracın gidiş istikametine göre sol taraftan yola girip karşıdan karşıya geçmekte olan ve üzerinde siyah mont bulunan M'ye çarpar. S, M'nin yola çıktığını fark eder, ancak aracı durduramaz. M, çarpmanın etkisiyle, çarpma noktasından 24 metre ileriye fırlar. S, buna rağmen durmayarak yoluna devam eder. Ertesi sabah saat 7.00 sıralarında yol kenarında ölü bulunan M, saat 08.50 de hastaneye getirilerek ölü muayene işlemine tabi tutulur. Saat 10.15'de düzenlenen ölü muayene tutanağında, ölümün ölü muayenesinin yapıldığı saatten 5 ila 7 saat önceki bir zaman diliminde gerçekleştiği belirtilir.

İlk Derece Mahkemesi bu olayda S'yi bilinçli **taksirle ölüme sebebiyet verme** suçundan mahkûm etmiştir. Buna karşılık, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, S'nin "*bir şahsa çarptığını bildiği, olay yerinde*

durup çarptığı kişiyi kontrol edip sağlık görevlilerini olay yerine çağırması ve kolluk görevlilerine haber vermesi durumunda ölenin hayatını kurtarma olanağı bulunmasına rağmen, olay yerinden hiç durmadan ayrıldığı, önceden gerçekleştirdiği bu davranışın başkasının hayatı için bir tehlike oluşturduğu ve bu fiilden kaynaklanan neticeyi önleme yükümlülüğü doğduğu halde, hareketsiz kalıp kimseye haber vermeyerek olay yerinden ayrılıp, bu imkânı kullanmadığı anlaşılmakla, ... eyleminin TCK'nın 83. maddesi" hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin bu mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu içtihadı doğrudur. Ancak söz konusu içtihadta, M'nin sadece **ihmalî davranışla** işlediği **kasten öldürme** suçundan dolayı mı, yoksa (bilinçli) **taksirle yaralamaya sebebiyet** verme suçunun yanı sıra, ihmalî davranışla işlediği kasten öldürme suçundan dolayı gerçek içtima hükümlerine göre mi cezalandırılması gerektiği hususuna açıklık getirilmemiştir. Belirtmek gerekir ki, bu olayda, S bakımından biri icraî, diğeri ihmalî davranışla gerçekleşmiş olan iki fiil mevcuttur.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin **5.9.2018** tarihli ve E. 2016/11297, K. 2018/7788 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, sürücü belgesi bulunmayan S, arkadaşının kimlik ve sürücü belgesi bilgilerini kullanarak, araç kiralama şirketinden kiraladığı araçla 28/02/2014 günü saat 19.00-19.30 saatleri arasında aydınlatmanın olmadığı, meskun mahal dışında, genişliği 10 metre, trafiğin tek yönlü işlediği bölünmüş, her iki yanında 50 km hız sınırının bulunduğu virajlı yolda seyir halinde iken, yolun sağında yürümekte olan M'ye çarpar ve durmadan olay yerinden uzaklaşır. M, ertesi gün sabah saatlerinde yol kenarında ölü olarak bulunur.

İlk Derece Mahkemesi bu olayda S'yi **taksirle ölüme sebebiyet verme** suçundan mahkûm etmiştir. Buna karşılık, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, S'nin "*sanığın bir şahsa çarptığını bildiği, olay yerinde durup çarptığı kişiyi kontrol edip sağlık görevlilerini olay yerine çağırması ve kolluk görevlilerine haber vermesi durumunda ölenin hayatını kurtarma olanağı bulunmasına rağmen, olay yerinden hiç durmadan ayrıldığı, önceden gerçekleştirdiği bu davranışın başkasının hayatı için bir tehlike oluşturduğu ve bu fiilden kaynaklanan neticeyi önleme yükümlülüğü doğduğu halde, hareketsiz kalıp kimseye haber vermeyerek olay yerinden ayrılıp, bu imkânı kullanmadığı anlaşılmakla, ... eyleminin TCK'nın 83. maddesi"* hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin bu mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

İlginçtir, Daire bu kararında S'nin sorumluluğunun belirlenmesi bakımından "*mağdurun olaydan sonra en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tedavisinin yapılması veya sanık tarafından sağlık görevlilerine haber verilmesi durumunda da ölüm sonucunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin tespit*" edilmesi gerektiği yönünde içtihadta bulunmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu tespitin ceza hukuku sorumluluğunun belirlenmesi bakımından bir önemi yoktur. Bunun "tespit"inin de sorun oluşturduğunu, esasında **fiktif** bir "değerlendirme"yi gerektirdiğini hatırlatmak gerekir.

Bu tür olaylarda kaza mahallinden ayrılan sürücünün sorumluluğu bakımından önemli olan, mağdurun ölüm anının tespitidir. Zira, mağdurun çarpmanın akabinde hemen ölmesi halindeki sorumluluk ile, sürücünün olay mahallinden ayrılmasından bir süre sonra ölmesi halindeki sorumluluğun dayandığı hükümler farklılık arz etmektedir.

Keza, Daire bu kararıyla, S'nin sadece **ihmalî davranışla kasten öldürme** suçundan dolayı ceza hukuku sorumluluğu yoluna gidilmesi gerektiği yönünde bir eğilim içinde olduğu izlenimi oluşturmuştur.

Söz konusu Kararda, S'nin arkadaşına ait kimlik bilgileri ile sürücü belgesini kullanarak araç kiralaması ile ilgili değerlendirme yapılmaması, önemli bir eksikliktir. Dikkat edilmelidir ki, S, arkadaşına ait kimlik bilgilerini kullanarak araç kiralamak için araç kiralama şirketi ile sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmenin imzalanmasıyla S, **özel belgede sahtecilik** suçunu (TCK, m. 207) işlemiştir.

⁵⁸⁹ Yargıtay 12. Ceza Dairesinin **22.11.2018** tarihli ve E. 2017/1521, K. 2018/11112 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, A'nın evine giderek kullanmak için uyuşturucu madde satın alan ve kolu alçıda olan B, satın aldığı uyuşturucuyu koluna şırınga ile enjekte etmesini A'dan ister. A, bu isteği yerine

Teminat yükümlülüğünün kaynağını oluşturabilmesi için ön gelen fiilin **hukuka aykırı** olması gerekir. Bu itibarla, örneğin meşru savunma halinde bulunan kişi, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla saldırganı yaralamış olabilir. Yaralanmak suretiyle saldırıya devam etme imkânı artık ortadan kalkmış olan saldırgana karşı, meşru savunmada bulunan kişi teminat yükümlülüğü altına girmemektedir. Bu itibarla, meşru savunmada bulunan kişi, yaralanan saldırganın tedavi edilmesini sağlamasa ve neticede saldırgan ölse, ihmali davranışla işlenmiş kasten öldürme suçundan (TCK, m. 83) dolayı sorumlu tutulmaz. Ancak bu durumda, aşağıda açıklanacağı üzere, meşru savunmada bulunan kişi yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçundan dolayı TCK, m. 98 hükümlerine göre ceza hukuku bakımından sorumlu tutulur.^{590 591}

getirir. Bunun üzerine rahatsızlanan ve A'nın evinde geceleyen B'nin sağlık durumu ilerleyen saatlerde kötüleşir. Ancak, A, durumu ilgili mercilere bildirmez. Durumu kötüleşen B, bilahare evde ölür.

İlk Derece Mahkemesi, A hakkında **taksirle ölüme sebebiyet verme** suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü kurmuştur. Buna karşılık, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, “iki kullanımlık doz uyuşturucunun ölenin isteği üzerine sanık tarafından ölenin koluna enjekte edildiği, sanığın bu davranışının ölenin hayatı için tehlikeli bir durum oluşturduğu, ayrıca enjeksiyon sonrası ölen fenalaştıktan ve beyanlara göre kendinden geçtikten sonra sanığın uyarılara rağmen ambulansa haber vermediği ve haber verilmesini de engellediği anlaşılmakla, sanığın ambulansa ve kolluk görevlilerine haber vermesi durumunda ölenin hayatını kurtarma olanağı bulunmasına rağmen ve kendisinin eyleminden kaynaklanan neticeyi önleme yükümlülüğü doğduğu halde, hareketsiz kalıp bu imkânı kullanmadığı anlaşılmakla, sanığın eyleminin TCK'nın 83. maddesinde belirtilen **kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi** suçu kapsamında değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu” gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Söz konusu olayda, A, **uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti** suçunu (TCK, m. 188, f. 3 vd.) işlemiştir.

A ayrıca, rızasıyla da olsa, B'nin vücuduna şırınga ile uyuşturucu madde enjekte etmek suretiyle, **kasten yaralama** suçunu (TCK, m. 86, 87) işlemiştir.

B, A'nın bu fiilinin neticesinde ölmüştür. Ölüm sonucu B'nin vücuduna uyuşturucu madde enjekte edilmesinin hemen akabinde gerçekleşmiş olsaydı, sorunu **neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama** suçu (TCK, m. 87, f. 4; m. 23) hükümleri çerçevesinde ele alıp değerlendirmek gerekirdi.

Oysa karara konu teşkil eden olayda, B, vücuduna uyuşturucu madde enjekte edildikten bir süre sonra ölmüştür. Başka bir ifadeyle, vücuduna uyuşturucu madde enjekte edilen B'nin sağlığının kötüleşmesine rağmen, ambulans çağırılmamış ve doğru olmayan yöntemlerle B iyileştirilmeye çalışılmıştır. Bu durumda, A, vücuduna uyuşturucu madde enjekte etmekle sağlığı bozulan B'ye karşı teminat yükümlülüğü altına girmiştir. Ön gelen fiili işleyen, yani B'nin vücuduna uyuşturucu madde enjekte eden A, sağlığı bozulan B'nin iyileşmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olmasına rağmen, bu yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmemiş ve sonuçta B ölmüştür. Bu durumda A'yı **ihmalî davranışla** işlediği **kasten öldürme** suçundan dolayı sorumlu tutmak gerekir. Dikkat edilmelidir ki, A'nın buradaki kastı doğrudan değil, **olası kasttır**.

Belirtilen eksikliklerin dışında, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin B'nin ölümünden dolayı A'nın sorumluluğu ile ilgili kararını doğru bulmaktayız.

⁵⁹⁰ ERBAŞ, Rahime: *Türk Ceza Kanunu'nda Görünüşte İhmalî Suçlarda Garantörlük*, İstanbul 2019, sh. 473; YURTLU, Doktora Tezi, sh. 225 vd.

⁵⁹¹ Doktrinde bazı yazarlar, bu durumda meşru savunmada bulunan kişinin hiçbir surette ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidilemeyeceği görüşündedirler (HAKERİ, Hakan: *Ceza Hukukunda İhmal*

Buna karşılık, karayolu trafik düzenine ilişkin kurallara aykırı herhangi bir davranışı bulunmamasına rağmen, bir başkasının kural ihlali sebebiyle kazaya karışan araç sürücüsü, bu trafik kazasında yaralanan kişilerle ilgili olarak teminat yükümlülüğü altına girmemektedir. Ancak bu sürücü, yaralanan kişilerle ilgili olarak yardım veya bildirim yükümlülüğü altındadır. Bu nedenledir ki, kazaya karışmış olmakla birlikte karayolu trafik düzenine ilişkin kurallara aykırı herhangi bir davranışı bulunmayan araç sürücüsü, bu trafik kazasında yaralanan kişilerle ilgili olarak yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, TCK, m. 98 hükümlerine göre ceza hukuku bakımından sorumlu tutulur.

Teminat yükümlülüğünün kaynağını oluşturan ön gelen fiil, en azından taksirli bir fiil olmalıdır.⁵⁹²

Teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesinin ihmali sonucunda meydana gelen ölüm neticesinden sorumluluk için, teminat yükümlüsünün (garantörün) somut

Kavramı ve İhmalî Suçların Çeşitleri, Ankara, Şubat 2003, sh. 174; KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler, 13. bası, sh. 410; aynı yazarlar, Özel Hükümler, 7. bası, sh. 143 vd.).

⁵⁹² Bir olayda, Devlet hastanesinde sağlık görevlisi olarak çalışan A, bakımını gerçekleştirdiği yeni doğmuş bebeğin ağzını temizlerken, temizlemekte kullandığı mendili boğazına kaçırır ve çıkarmaya çalışırsa da başarılı olamaz. Ancak, durumla ilgili olarak kimseye bilgi vermez. Bu nedenle bebeğin sağlık durumu kötüleşir ve birkaç gün sonra bebek ölür. Yapılan tetkiklerde bebeğin ölümüne, boğazına kaçırılan mendilin sebep olduğu anlaşılır.

Konya Devlet Hastanesinde sağlık görevlisi olarak çalışan A, henüz yeni doğmuş olan çocuğun bakım ve hizmetini yaparken, kullandığı mendili bebeğin boğazına kaçırır. Mendilin bebeğin boğazına kaçmasına sebebiyet veren A'nın, mendili çıkaramaması üzerine, durumdan ilgili hekimi derhal **bilgilendirme yükümlülüğü** doğmuştur (TCK, m. 83, f. 2, bent b). Bu durum karşısında, **takaddüm eden, ön gelen fiile bağlı bildirim yükümlülüğünü** yerine getirmeyen A bakımından **ihmalî davranışla işlenmiş kasten öldürme** suçundan dolayı sorumluluk yoluna gidilmelidir (TCK, m. 83).

Hastanede görevine devam eden A, bebeğin sağlık durumunun kötüleştiğini müşahade etmesine rağmen, bunun sebebiyle ilgili olarak hekimleri bilgilendirmekten imtina etmiştir. Bu itibarla, A, bebeğin bu sebeple ölebileceğini öngörmüştür; ancak buna rağmen bebeğe gerekli tıbbi müdahalenin yapılmasını sağlamaya yönelik olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Bu durumda, bebeğin ölümü bakımından A'nın **olası kast**ının varlığını kabul etmek gerekir.

Bu durumda, A hakkında kasten öldürme suçunu ihmali davranışla işlemesi dolayısıyla verilecek **temel ceza**, mağdur **çocuk** olduğu için, TCK, m. 82, f. 1, bent e hükmüne istinaden **ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır**. Suçun olası kastla işlenmesi sebebiyle bu ceza yerine A hakkında TCK, m. 21, f. 2 hükmüne istinaden **müebbet hapis cezasına** hükmedilecektir.

Kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde cezada indirim yapıp yapmama konusunda mahkemenin **takdir** yetkisi bulunmaktadır. Mahkemenin, takdir yetkisini A'nın cezasında indirim yapma yönünde kullanması halinde, TCK, m. 21, f. 2 hükmüne istinaden belirlediği ceza yerine, TCK, m. 83, f. 3'de yer alan ikinci alternatif çerçevesinde **on beş yıl ile yirmi yıl arasında bir cezaya** hükmetmesi gerekir.

A, yaptığı bu yanlış karşısında korktuğu için durumdan hekimleri bildirmekten imtina etmiş olsa bile, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dolayı değil, kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi dolayısıyla cezalandırılması gerekmektedir. Bu korku halinin, A'nın kusurluluğu ve TCK, m. 83, f. 3'de yer alan ikinci alternatif çerçevesinde cezasının belirlenmesi bağlamında dikkate alınması gerekmektedir.

olay bağlamında bu yükümlülüğün gereğini yerine getirme **imkânının** olması gerekir. Örneğin denizde yüzmekte olan çocuğunun boğulma tehlikesi geçirmekte olduğunu görmesine rağmen yüzme bilmediği için denize giremeyen ve çocuğunu kurtarabilmesi için başka bir imkânı bulunmayan baba, çocuğunun boğularak ölmesinden dolayı TCK, m. 83 hükümlerine istinaden cezalandırılmaz.

Klasik suç teorisinde, ihmalî davranışla gerçekleşen netice arasında illiyet bağının var olduğu fikri kabul edilmektedir.⁵⁹³ Ancak, bu düşünce illiyet bağı fizikî ve dolayısıyla, doğal bir olgu olarak değil, “*düşünce aleminde kurulan bir bağ*” olarak görmektedir.⁵⁹⁴

Gerçekleşen netice dolayısıyla ceza sorumluluğu için, bu neticenin kişiye objektif olarak isnat edilmesi gerekir (**objektif isnadiyet**). Ancak, bu isnadiyeti doğal bir olgu olarak izah etmek mümkün değildir. Belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğü altında bulunan kişi ile ortaya çıkan neticeyi birbirleriyle ilişkilendirmek, ancak *normatif bir değerlendirmeye* mümkün olabilir.⁵⁹⁵ Bu bakımdan, **görünüşte ihmalî suçlarla ilgili olarak, doğal bir fenomen olan nedensellik bağından söz edilemez.**⁵⁹⁶ Aynı değerlendirmeler, taksirli suçun ihmalî davranışla işlenmesi bakımından da geçerlidir.⁵⁹⁷

Önemle belirtmek gerekir ki, özellikle ön gelen fiil dolayısıyla teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu durumlarda, failin ön gelen fiiliyle örneğin ölüm neticesi arasında doğal bir fenomen olarak nedensellik bağı bulunmaktadır.

Meydana gelen neticeden kişiyi sorumlu tutabilmek için, **somut olayda kişinin bu neticeyi önlemeye yönelik icraî davranışta bulunma hususunda imkân ve iktidara sahip olması gerekir.** Aksi takdirde, kişi meydana gelen neticeden sorumlu tutulamaz.

⁵⁹³ DÖNMEZER/ERMAN I, no. 612 vd.; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 105. “Bir kimsenin zararlı sonucu önlemek elinde iken, bunu yapmaması” halinde illiyet bağı vardır: EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 286/287.

⁵⁹⁴ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 123; ÇINAR, Ön Kusurluluk, sh. 57.

⁵⁹⁵ MAIWALD, Manfred: *Handeln und Unterlassen - Handeln für einen Anderen (İcraî ve ihmalî Davranış - Bir Başkası için Hareket Etmek)* (Çeviri: Cumhur Şahin), in: Türk Ceza Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler, Konya 1998, sh. 143 vd., 159 vd. *Yurtlu*’nun objektif isnadiyet bağlamında verdiği trafik kazası örneğine ilişkin olarak yaptığı açıklamalar, sorunludur (YURTLU, Doktora Tezi, sh. 261 vd.).

⁵⁹⁶ Ancak Yargıtay, görünüşte ihmalî suçlar bakımından “*doğal anlamda değil, normatif anlamda nedensellik bağı*” ibaresini kullanmaktadır: CGK, 9.12.2014, E. 2014/12-103, K. 2014/552. Hatta, *Hakerî*, gerçek ihmalî suçlarda da nedensellik bağının bulunduğu, ancak bu suçların “neticesi harekete bitişik suçlar” olduğu için, bu bağın aranmasının pratik bir öneminin olmadığı görüşündedir (HAKERÎ, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmalî Suçların Çeşitleri, sh. 225). Keza, *Yurtlu*, ontik bir vakıa olarak gördüğü ihmalî davranış ile meydana gelen netice arasında doğal bir fenomen olarak nedensellik bağının varlığı düşüncesindedir (YURTLU, Doktora Tezi, sh. 246 vd.).

⁵⁹⁷ *Yurtlu*, taksirle ve ihmalî davranışla bir başkasının ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet verilmesi halinde, TCK’nın düzenlemesi itibarıyla, m. 85 veya 89 hükümlerine istinaden cezalandırmanın, suçta kanunilik ilkesiyle bağdaşmadığı görüşündedir (YURTLU, Doktora Tezi, sh. 278).

Kişi, yerine getirme imkânı olmadığı bir yükümlülüğe uygun davranmadığı için muaheze edilemez. Yükümlülüğün gereğini yerine getirmemesi dolayısıyla kişinin muaheze edilebilmesi için, bunu yerine getirme imkânına fiilen sahip olması gerekir.⁵⁹⁸ Bu fiili imkân, somut olayda ihmalî suça ilişkin kusur kapsamında mütalaa edilmelidir. Başka bir deyişle, somut olayda kişi, belli bir yönde icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün varlığına rağmen, bu yükümlülüğün icaplarına göre hareket etme imkân ve iktidarına sahip olmayabilir. Belli bir yönde icraî davranışta bulunmak hususunda yükümlülüğe rağmen, bu yükümlülüğün gereğinin yapılması, ihmalî suçun haksızlık muhtevasını oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, yükümlülüğe rağmen muayyen icraî davranışın gerçekleştirilmemesi durumunda, hukuka aykırılık gerçekleşmiştir.⁵⁹⁹ Ancak, bu hukuka aykırılık dolayısıyla kişinin kusurlu addedilebilmesi için, belli bir yönde icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün icaplarına uygun hareket etme imkân ve iktidarına sahip olmasına rağmen, yükümlülüğün gereğini yerine getirmeyi ihmal etmiş olması gerekir.⁶⁰⁰

Kişinin, belli bir yönde icraî davranışta bulunma hususundaki yükümlülüğü açısından, irade serbestisine sahip olması gerekir. Yükümlülüğün icaplarına uygun davranma hususunda fiili imkânsızlığın mevcut olduğu durumlarda bu irade serbestisinden söz edilemez. Kişide bu imkân ve iktidarın var olup olmadığı, ex ante (yani olayın oluş şartları itibarıyla) bir değerlendirmeye tespit edilecektir.

Kişinin neticeyi önlemeye yönelik icraî davranışta bulunmasına rağmen, netice gerçekleşmiş olabilir. Kişi, sahip bulunduğu imkânlar ölçüsünde neticenin meydana gelmemesine gayret etmiştir; ancak, buna rağmen netice gerçekleşmiştir. Bu durumda, kişi meydana gelen neticeden sorumlu tutulamaz.

Somut olayda neticeyi önlemeye yönelik icraî davranışta bulunma hususunda imkân ve iktidara sahip olmasına rağmen, kişi bu yükümlülüğe aykırı hareket etmiş ve netice gerçekleşmiştir. Bu gibi durumlarda kişi, somut olayda söz konusu yükümlülüğe uygun davranışta bulunsaydı dahi bu netice gerçekleşecekti şeklinde bir mantıktan hareketle sorumluluktan kurtulamaz.^{601, 602}

⁵⁹⁸ HAKERİ, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmalî Suçların Çeşitleri, sh. 247.

⁵⁹⁹ Nitekim Kunter, belli bir yönde icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün ihmalî suçlarda hukuka aykırılık unsurunu oluşturduğunu ileri sürmektedir (KUNTER, Suçun Maddi Unsurları, sh. 213).

⁶⁰⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz. YURTLU, Doktora Tezi, sh. 177 vd.

⁶⁰¹ Aksi yöndeki kabul için bkz. Yargıtay 1. CD, 9.3.2016, E. 2015/5441, K. 2016/1144. Keza, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen “Marmara depremi”nde yıkılan binaların enkazında hayatını kaybeden binlerce kişinin ölümü dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ceza hukuku bilim dalında “profesör” unvanı taşıyan bazı kişilerin düzenledikleri “bilirkişi” raporlarında, söz konusu yanlış mantıktan hareketle, bu binaları inşa eden müteahhitlerin ceza hukuku bakımından sorumlu tutulmamaları gerektiği yönünde görüş beyanında bulunulmuştur.

⁶⁰² Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 9.12.2014 tarihli ve E. 2014/12-103, K. 2014/552 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Ankara’da cuma günü geçirdiği trafik kazasında yaralanan Y, tedavi amacıyla ... Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılır.

Önce Acil Serviste müdahale edilen hasta Ortopedi ve Travmatoloji Servisine sevk edilir. Burada yapılan muayenesinin akabinde “*ortopedik olarak acil cerrahi bir müdahaleye gerek olmadığından yatış*”ı yapılmaz ve Üroloji Servisine sevk edilir. Bu Serviste yapılan muayene-nin akabinde de hastanın yatışı yapılmaz ve taburcu edilir.

Ancak, Üroloji Servisinden hastanın muayenesine yapan uzman hekim bilahare telefonla hasta yakınlarını arayarak, hastanın idrar yapıp yapmadığını sorar, aldığı cevap üzerine, hastanın idrar-ını kendisinin yapabileceğini, bir sorun olursa pazartesi günü polikliniğe getirmelerini söyler.

Y, evde yediği yemeği istifra ederek çıkarır. Akşamın ilerleyen saatlerinde yakınları telefonla hastaneyi arayarak, hastanın kusmalarının ara ara devam ettiğini ve idrarının kanlı geldiğini söylerler. Hastane görevlisi cevap olarak onlara o an için hastanede üroloji doktoru olmadığını gerekirse hastayı başka bir hastaneye götürebileceklerini söyler. Cumartesi sabah erken saatlerde hastanın rahatsızlıklarının artması üzerine, yakınları bu defa ... Numune Hastanesini telefonla ararlar. Telefonla görüştükleri görevli kendilerine hastayı daha önce götürmüş ol-dukları hastaneye götürmelerini tavsiye eder. Bu sırada Y ölür.

Y’ye tıbbi müdahalede bulunan hekimler hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dolayı soruşturma yapılır ve kamu davası açılmıştır.

Bu süreçte Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesi tarafından Y’nin ölüm sebebine ilişkin olarak düzenlenen Raporda, trafik kazası sonucu yaralanması nedeniyle götürüldüğü hastanede yapılan muayeneleri sonucunda acil cerrahi girişim gerektirecek patoloji saptanmadığı belirtilerek tabur-cu edilen Y ile ilgili uygulamaların tıp kurallarına uygun olarak yapıldığı, ölüm nedeninin **akci-ğer embolisi** olduğu ve **bunun da önceden öngörülecek ve engellenebilecek bir durum ol-madığı**; “*ancak bu tür genel beden travmasına maruz kalmış vakaların en az 24 saat müşahede altında tutulması gerektiği, dolayısı ile kişinin konsültasyonlar yapıldıktan 6-7 saat sonra ta-burcu edilmesinin tıp kurallarına uygun olmadığı, bunun bir eksiklik olduğu*” belirtilmiştir.

Yüksek Sağlık Şurasının kararında ise, uzman hekimlerin Y’nin vücudundaki kemik kırıklarını tespit etmelerine rağmen, düzenledikleri konsültasyon notlarında hastanede takibinin gerektiğini belirtmedikleri ve takibini yapmadıkları gerekçesiyle “kusurlu” oldukları kabul edilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi, bu olayda sanık hekimlerin tedavileriyle Y’nin ölümü arasında **ne-densellik bağının bulunmadığı** gerekçesiyle beraatlerine hükmetmiştir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi,

“*gerekli takip ve tıbbi müdahale yapılırsa dahi ölüm neticesi gerçekleşeceğinden, sanıklara atılı taksirle öldürme suçu yasal unsurları itibarıyla oluşmamış ise de; ölen hastasının zarar görmemesi için mesleki tüm şartları yerine getirmek, tıbbi açıdan zamanında teşhis koyup, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak zorunda olan sanık doktorların, görevlerinin gereklerini yerine getirmede ihmal gösterdiklerinin sabit olması karşısında, TCK’nın 257/2. maddesinde tanımlanan görevi kötü-ye kullanma suçundan mahkûmiyetlerine karar verilmesi*” gerektiği gerekçesiyle,

İlk Derece Mahkemesinin beraat hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

İlk Derece Mahkemesi, aşağıdaki gerekçe ile bu bozma kararına karşı direnmiştir:

“*TCK’nın 257. maddesinin gerekçesinde, görevi kötüye kullanma suçunun genel, tali ve tamam-layıcı bir suç tipi olduğu, bu nedenle görevin gereklerine aykırı davranışın başka bir suçu oluş-turmadığı hallerde, kamu görevlisini bu suçtan cezalandırmak gerektiği, buna karşılık görevle bağlantılı yükümlülüğün ihmalî sonucunda şayet bir kişi ölmüş veya yaralanmış ise kişilerin ar-tık görevi kötüye kullanma suçundan dolayı cezalandırılmayacakları, bu durumda, ihmalî dav-ranışla işlenmiş öldürme veya yaralama suçunun oluştuğunu kabul etmek gerektiği belirtilmiştir.*

...

Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanıkların kusuru sonucu müteveffa olmamış emboli sonu-cu ölmüştür. Hastanede müşahade altına alınmış olsa dahi aynı ölümün kaçınılmaz oldu-

ğunun kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle her ölüm olayından ölüye şu veya bu şekilde müdahale eden bir hekimi sorumlu kılmak meslek ve sanatın yapılmasını sektete uğratar. Bu alanda çalışanların şevki kırılır, sonuç doğurucu ve hayata döndürücü girişimlere yönelmelerini engeller. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi 1219 sayılı Kanunun Yüksek Sağlık Şurasının mütalaa verme yetkisini düzenleyen 75. maddesini ... iptal etmiştir.

Bu iptal karşısında Yüksek Sağlık Şurasının dosyada bulunan mütalaasını kabul etmek olanaksızdır. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu da **sanıklara atfedilen eksikliğin ölüme katkısının bulunmadığını** belirtmiş ve sanıkların suç işleme kasıtlarının bulunmadığını, kusurlarının olmadığını belirtmiştir.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise, nedensellik bağı, ihmalî suçlar ve taksirli suçlar konusunda çeşitli doktorlar açıklamaları gereksiz yere iktibas etmenin yanı sıra, aşağıdaki gerekçe ile, İlk Derece Mahkemesinin beraat hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

“Doktor olarak görev yapan sanıkların, taksirle yaralanma nedeniyle acil servise müracaat eden ölene yönelik yaptıkları muayene ve istedikleri tetkiklerle ölenin çoklu pelvis kırığı, çoklu kot kırıkları ve kanlı idrar yaptığını tespit ettikten sonra acil cerrahi müdahaleyi gerektirir patoloji bulunmadığına karar vermiş olmalarının dosyadaki raporlara göre tıp kurallarına uygun olduğu, bununla birlikte **genel beden travmasına ve çoklu kemik kırıklarına maruz kalmış öleni** Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 24/2. maddesi uyarınca stabilizasyonu sağlanıncaya kadar ve tıp çevrelerinde genel olarak kabul gördüğü şekilde **24 saat müşahede altında tutmaları gerekirken** 6-7 saat içinde taburcu etmeleri nedeniyle olayda görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal gösterdikleri, ancak **bu davranışları ile meydana gelen ölüm neticesi arasında nedensellik bağının bulunmadığı**, başka bir anlatımla sanıklarının ihmalî davranışlarının ölüme neden olacak nitelikte bulunmadığı, zira ölümün genel beden travması nedeniyle öngörülemez ve engellenemeyecek biçimde ortaya çıkan akciğer embolisi komplikasyonu nedeniyle gerçekleştiğinin bilirdiği raporlarıyla kesin olarak belirlendiği, bu nedenle **sanıkların ölüm sonucundan sorumlu tutulamayacakları**, bununla birlikte genel beden travmasına maruz kalmış öleni erken taburcu etmek suretiyle görevlerinin gereklerini yerine getirmekte ihmal gösterdikleri, bu ihmal nedeniyle ölenin ölüm anına kadar yaşadığı çeşitli sıkıntılara maruz kalmasına diğer bir deyişle mağduriyetine sebep oldukları anlaşıldığından, sanıkların eylemlerinin TCK’nın 257/2. maddesi kapsamında görevi ihmal suçunu oluşturduğu ve bu suçtan mahkûmiyetlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden beraatlerine karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu kararı oyçokluğu ile vermiştir. Başkan ve bir kısım Üyeler,

“Ölümün öngörülemez ve engellenemeyen akciğer embolisi nedeniyle gerçekleşmiş olmasına göre, sanıkların öleni 24 saat müşahede altına tutmaları halinde bile sonucun değişmeyeceği, bu itibarla sanıkların kasıtlı bir suç olan TCK’nın 257/2. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanmak suçundan sorumlu tutulamayacakları” ve bu nedenle, “sanıkların beraatlerine yönelik direnme hükmünün yerinde olduğu”

gerekçesiyle karşı oy kullanmışlardır.

Hukuki değerlendirmemiz:

Öncelikle belirtmek gerekir ki, karara konu teşkil eden olayda, **nedensellik bağı sorunu bulunmamaktadır.** Trafik kazasında yaralanan Y’nin vücudunda çeşitli kemik kırıklarının oluştuğunun tespit edilmesine rağmen, gerekli müşahede ve tedavi sürecine tabi tutulmadan hastaneden taburcu edilmiştir. Trafik kazasında yaralanan hasta, kaldırıldığı hastanede gerekli müşahede ve tedaviye tabi tutulmaması sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle, İlk Derece Mahkemesinin beraat hükmü gibi, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin ve aynı doğrultudaki Yargıtay Ceza Genel Kurulunun söz konusu olayda nedensellik bağının bulunmadığı gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun oluşmadığı yönündeki kararları hukuken sorunludur.

Trafik kazası gibi fizikî travmaya maruz kalan hasta, tıp biliminin gereği olarak yirmi dört saat süreyle müşahede altında tutulması gerekirken, vücudunda çeşitli kemik kırıklarının olduğu tespit

III. Teminat yükümlülüğünün ihlali sadece kasten öldürme suçundan sorumluluk bağlamında değil, **kasten yaralama** suçundan sorumluluk bağlamında da dikkate alınmaktadır (TCK, m. 88).

IV. TCK, m. 84’de tanımlanan **intihara yönlendirme suçu**, ihmali davranışla da işlenebilir.

Bir “başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi,” TCK, m. 84 hükümlerine göre cezalandırılır. Bu yardım, icraî davranışla olabileceği gibi, ihmali davranışla da olabilir. Bu itibarla, intihar girişiminde bulunanla ilgili olarak koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişi, bu **intihar girişimini önlememek suretiyle intihara yardım** etmiş olur. Söz konusu madde gerekçesinde yer alan şu açıklamalar, bu konuda yol göstericilik özelliği taşımaktadır: “*intiharı önleme konusunda hukukî yükümlülük altında bulunan kişinin, bir in-*

edilmesine rağmen, müşahedeye ve gerekli tedaviye tabi tutulmaksızın hastaneden taburcu edilmiştir. Bu itibarla, hastanın akciğer embolisi sonucu ölmesinin müşahade ve tedavi görevini yerine getirmeyen hekimlere **objektif** olarak **isnadiyetinde** bir sorun bulunmamaktadır.

Ayrıca, fiziki travmaya maruz kalan hasta ile ilgili olarak müşahade yükümlülüğünün varlığının kabul edilmesine rağmen, “ölümün genel beden travması nedeniyle öngörülemeyecek ve engellenemeyecek biçimde ortaya çıkan akciğer embolisi komplikasyonu nedeniyle gerçekleştiğin”den bahisle, “sanıkların ölüm sonucundan sorumlu tutulamayacakları”nın kabulü, bir **çelişkiyi** ifade etmektedir. Bir taraftan müşahade yükümlülüğünden, diğer taraftan “öngörülemeyecek ve engellenemeyecek” akciğer embolisinden söz etmek, bünyesinde bir çelişki barındırmaktadır.

Keza, aynı zamanda kamu görevlisi olan sanıkların görevi kötüye kullanma suçundan mahkûm edilmeleri gerektiği yönündeki Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu Kararları hukuken sorunludur. Görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler, genel, tali ve tamamlayıcı hükümlerdir. Kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi, şayet başka bir suçu oluşturmuyorsa ve özellikle, belirli objektif cezalandırılabilme şartlarından birinin gerçekleşmesine bağlı olarak görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilir (Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *İrtikâp, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları*, 2. bası, Ankara, Haziran 2013, sh 149 vd.). Bu yönü itibarıyla İlk Derece Mahkemesinin direnme kararının gerekçesi doğrudur.

Bu olay bağlamında sorun, sadece hekimlerin hastaya müdahalesindeki eksiklik ve yanlışlıklarda değildir. Aynı zamanda hasta yakınları da kendilerine terettüp eden yükümlülüğü yerine getirmemişlerdir. Taburcu edilen hastada kusmaların başlamasına ve hastanın idrarının kanlı geldiğini görmelerine rağmen, hastayı derhal aynı veya başka bir sağlık kuruluşuna ulaştırma yönünde girişimde bulunmamışlardır. Bu süreçte hastanelerin telefonla aranarak görevli memurlarla görüşme yapılması ile, bu yükümlülüğün gereği yerine getirilmiş olmamaktadır.

Bu itibarla söz konusu olayda taksirle yaralamaya ve taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı farklı kişilerin kendilerine terettüp eden yükümlülükleri ihlallerinden dolayı kendi kusurları çerçevesinde ceza hukuku bakımından sorumlu tutulmaları gerekirdi (TCK, m. 22, f. 5). Ancak bu bağlamda hasta yakınları ile ilgili olarak TCK, m. 22, f. 6’daki şahsi cezasızlık sebebini göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu olay bakımından dikkate alınması gereken diğer husus ise, trafik kazası ile Y’nin yaralanmasına sebebiyet veren kamyon sürücüsünün hangi suçtan sorumlu tutulması gerektiğidir. Bu gibi durumlarda kamyon sürücüsünün taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı mı yoksa taksirle yaralamaya sebebiyet vermekten dolayı mı sorumlu tutulması gerektiği bir sorundur. Hukuk uygulamamız, trafik kazasına sebebiyet veren kişiyi, kazada yaralanan kişi bilahare hastanede yanlış veya eksik tedavi sonucunda ölmüş olsa bile, taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı sorumlu tutmaktadır. Bu uygulamanın da doğru olmadığını düşünmekteyiz.

*tiyar olgusuyla karşı karşıya olmasına rağmen, bu intihar girişimini engellememesi, bu girişim karşısında kayıtsız davranması; **intihara ihmali davranışla yardım** olarak nitelendirilmek gerekir. Ancak, bunun için, kişinin intiharı önleme konusunda hukuki bir yükümlülüğünün olması gerekir.”⁶⁰³*

Belirtmek gerekir ki, ilgili kamu görevlilerinin intihar girişiminde bulunan tutuklu, hükümlü veya asker kişi bakımından kanun gereği olarak **koruma ve gözetim (teminat) yükümlülüğü** bulunmaktadır. Bir intihar girişimi karşısında bu koruma ve gözetim yükümlülüğünün **kasten** yerine getirilmemesi halinde, ilgili kamu görevlisinin **kasten öldürme suçunu ihmali davranışla işlemekten** dolayı sorumluluğu cihetine gidilmesi gerektiği düşünülebilir⁶⁰⁴ ise de, özel hüküm mahiyeti taşıyan TCK, m. 84 hükümlerini göz önünde bulundurmak ve uygulamak gerekir.

TCK, m. 84 hükümlerini, eşlerden birinin intihar girişimi karşısında kayıtsız kalan diğer eşin ceza hukuku sorumluluğu bağlamında da dikkate almak gerekir.

İntihara yönlendirme suçunun oluşabilmesi için, intihara en azından teşebbüs edilmesi gerekir. Bu suçun temel şekli bakımından **intihara teşebbüs edilmesini**, nite likli hali bakımından ise, **intiharın gerçekleşmesini** (TCK, m. 84, f. 2), bir **objektif cezalandırılabilme şartı** olarak aramak gerekir. Bu yönü itibarıyla, söz konusu suçun temel şekli, bir **somut tehlike suçu** mahiyeti taşımaktadır.^{605,606}

⁶⁰³ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 488 vd.

⁶⁰⁴ Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 1.7.2021 tarihli ve 2020/4794, K. 2021/11661 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, S, zaman zaman şiddet uyguladığı eşi M ile arasında gece saatlerinde çıkan tartışma sırasında eşinin yüzüne tokat atar. Bunun üzerine M, fazla dozda ilaç alarak intihar etmeye teşebbüs eder ve fakat, bu girişiminden pişmanlık duyarak, S’den kendisini hastaneye götürmesini ister. Ancak, S bu talebe icabet etmediği gibi, eşi M’nin telefonla başkalarından yardım istemesini de engeller. M, sabah saatlerinde S’nin işe gitmesinden istifade ederek bir şekilde ulaştığı komşularının yardımı ile hastaneye kaldırılır ise de, aldığı ilaçların etkisiyle hayatını kaybeder.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, bu olayda hakkında **ihmalî davranışla kasten öldürme suçunu** işlemekten dolayı kamu davası açılan S’nin, M’nin intiharından sorumlu tutulamayacağını kabul ederek **beraatine** hükmetmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise bu olayda, diğer bir sebebin yanı sıra, “**maktulün sanık tarafından hastaneye götürülmesi halinde ölüm sonucunun doğup doğmayacağı ve zamanında hastaneye götürülmemesi nedeniyle tedavinin imkansız hale gelip gelmediği hususunda Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan rapor alınması, bu noktada ölüm ile sanığın ihmali eylemi arasında illiyet bağı kurulup kurulamayacağı hususunun belirlenmesi**” gerektiği gerekçesiyle, bozma kararı vermiştir.

Hemen belirtmek gerekir ki, bu karar, sonucu itibarıyla doğru olmakla birlikte, gerekçesi itibarıyla sorunludur. Nedensellik bağı sorunu bulunmayan bu olayda S’nin, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan değil, **icraî davranışla kasten öldürme suçunun** nitelikli halinden dolayı sorumlu tutulması gerekir.

⁶⁰⁵ TULAY, Muhammet Emre: *Türk Ceza Hukukunda İntihara Yönlendirme Suçu*, in: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt 26, sayı 2, Aralık 2020, sh. 814 vd., 817.

⁶⁰⁶ Talep üzerine öldürme fiili, çeşitli ülke ceza kanunlarında suç olarak tanımlanmıştır. Bu ülkelerden biri de Almanya’dır.

Alman Ceza Kanunu, § 216 hükmüne göre, **her kim, bir başkasını, açık bir şekilde ve ciddiyetle ifade ettiği talebi üzerine öldürürse, cezalandırılır.** Talep üzerine öldürme, kasten öldürme suçuna (§ 212) nazaran daha az ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Bu hükümle yaptırım altına alınan, talebi üzerine bir başkasını öldürme fiilidir. Kişi, kendisini öldürmesi için bir başkasından talepte bulunmaktadır. Talepte bulunulan da, bu talep üzerine, talepte bulunanı öldürmektedir. Kasten öldürme suçuna nazaran daha hafif ceza ile cezalandırılmayı gerektiren söz konusu madde hükmüne göre, talepte bulunanın talebinin açık seçik ve ciddi olması gerekmektedir.

Bu madde hükmünün uygulanabilmesi için, talepte bulunanın mesela, ağır hasta olması, hastalığının tedavisinin bulunmaması, hastalığı dolayısıyla katlanılmaz ağrılar hissetmesi gibi etkenlerin varlığına gerek bulunmamaktadır.

Bu suç bakımından özellik arz eden husus, öldürme fiilinin bir başkası tarafından gerçekleştirilmesidir. Her ne kadar kişinin isteğine bağlı ise de, bir başkası, bu istek üzerine, istekte bulunanı öldürmektedir.

Alman Ceza Kanunu, § 217'de ise, 3.12.2015 tarihli değişiklikle, **iş edinilerek, başkalarının intihar etmesine imkân sağlanması veya yardımcı olunması** suç olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu hükme göre, **her kim, intihara teşvik amacıyla ve bunu iş edinerek, bir başkasının intihar etmesine imkân sağlar veya yardımcı olursa, cezalandırılır.** Ancak, bir başkasını intihara teşvik **iş edinilmemiş** ise veya intihar eden ile **akrabalık, yakınlık ilişkisinin** varlığı halinde, cezaya hükmolunmaz.

Bu hükümde, ancak **iş edinilerek** bir başkasının intihara teşvik edilmesi, yönlendirilmesi, intiharına imkan sağlanması, yardım edilmesi suç olarak tanımlanmıştır. Buna karşılık, **iş edinilmeksizin**, bir başkasının intihara teşvik edilmesi, yönlendirilmesi, intiharına imkan sağlanması, yardım edilmesi, suç oluşturmamaktadır.

10.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren 3.12.2015 tarihli Kanunla (Bundesgesetzblatt [BGBl.] I, sh. 2177) yapılan bu düzenlemeye göre, bir başkasının intiharına yardım, belirli koşullarda suç oluşturmaktadır. Bu düzenleme ile, bir başkasının intiharına yardım, Alman hukukunda ilk defa suç olarak tanımlanmıştır. Ancak söz konusu düzenleme, **Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin 26.2.2020 tarihli Kararı ile Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir** (2 BvR 2347/15; 2 BvR 651/16; 2 BvR 1261/16; 2 BvR 1593/16; 2 BvR 2354/16; 2 BvR 2527/16 sayılı Dosyalarla ilgili Karar).

Alman hukukuna göre, bir başkasının intiharına yardım etmek, ceza sorumluluğunu gerektirmemektedir. Zira, intihar etmek, suç oluşturmaz için, buna yardım etmek de suç oluşturmamaktadır. Alman hukukunda, kişinin **kendi geleceğini belirleme hakkının** (*Selbstbestimmungsrecht*) intiharı da kapsadığı kabul edilmektedir.

İntihara yardım ile, bir başkasının ölümüne yardımcı birbirine karıştırmamak gerekir. Ölümüne yardım etmede, kişi, icra ettiği davranışlarla bir başkasının hayatına son vermektedir. Kişi, bir başkasının hayatına son vermeye yönelik davranışlar üzerinde hakimiyet tesis etmektedir.

Ölüm döşğinde yatan hastanın ölümünü hızlandırmasının öngörülmesine rağmen, ağrıların dindirilmesi amacıyla uygulanan ilaç tedavisi, aslında dolaylı olarak ölümüne yardım mahiyeti taşımaktadır. Keza, bir hastanın hayata tutunmasını sağlayan bir tedaviye son verilmesi halinde de dolaylı bir şekilde ölümüne yardım söz konusudur. Kısaca belirtmek gerekir ki, bu fiiller, ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmemektedir. Bu istisnalar dışında, bir başkasının ölümüne yardımda bulunmak, Alman hukukunda **talep üzerine öldürme** suçuna ilişkin hükümlerin uygulanmasını gerektirmektedir.

Alman Ceza Kanunu § 217'de tanımlanan suç, bir **soyut tehlike suçu** mahiyeti taşımakta idi. Zira söz konusu suçu oluşabilmesi için, bir başkasının intihara teşvik edilmesi, yönlendirilmesi, intiharına imkan sağlanması, yardım edilmesi neticesinde intiharın gerçekleşmesi ve hatta intihara teşebbüs edilmesi gerekmemekte idi.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, sorumluluk bilinciyle hareket edebilen ve kendi geleceği ile ilgili olarak serbestçe karar verme yetisine sahip bulunan bir kişinin hayatına son verme yönündeki kararını, Alman Anayasası ile koruma altına alınmış olan kişilik hakkının kullanılmasının bir yansıması olarak değerlendirmiştir (kn. 201 vd.). Keza, bir başkasının intihar etme yönündeki kararının icrasına yardımda bulunma fiilleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir (kn. 203).

İnsan onuru, dokunulmazdır ve devlet gücünün kullanılmasında riayet edilmesi ve korunması gereken bir değerdir.

Kişi, kendi şahsiyetini serbestçe tekâmül ettirme ve kendi geleceğini serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Bu hak, insan onurunun güvence altına alınmasını, özgür kişilik sahibi ve dokunulmaz olmasını ifade etmektedir. Keza, vazgeçilemez olan insan onuru, devletin tasarrufları bağlamında insanın salt bir obje durumuna irca edilmemesini gerektirmektedir.

Kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı, kendi belirlediği ölçütler çerçevesinde vücudu üzerinde tasarrufta bulunma yetkisini ve keza, kendi yaşantısıyla, kendi dünya görüşü ile, kendi anlayışıyla bağdaşmayan, çelişen bir hayat tarzını benimsemeye zorlanamayacağı da kapsamaktadır (kn. 207).

Almanya Federal Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararına göre, kişinin muhtariyetini ifade eden genel kişilik hakkı, **hayatına son verme hakkını** da kapsar. Keza, bu temel hak, diğer bir kişiden intihar konusunda yardım talebinde bulunma ve hatta, yardım etme konusunda teklifte bulunan kişilerin teklifini kabul etme özgürlüğünü de bünyesinde barındırır (kn. 208 vd.). Birey bakımından hayatın ne anlam taşıdığı, hayatiyetini devam ettirip ettirmemesi, hangi mülahazat ile hayatiyetine son vermeyi istediği hususları, kişiye sıkı sıkıya bağlı olan düşünce ve kanat hürriyetinin kapsamında mütalaa edilmelidir (kn. 209).

Kişinin hayatiyetine son verme hakkı, örneğin tedaviyi reddetmesi gibi, hayatiyetinin devam edebilmesi için gerekli olan tedbirlerin alınmasını reddetme hakkı ve bu suretle, yakalandığı ölümcül hastalığın kendi seyrine bırakılmasını isteme hakkı ile sınırlı tutulamaz (kn. 209).

Kişinin hayatiyetine son verme hakkı, haricen belirlenen durumlarla sınırlandırılmaz, kısıtlanamaz. Kişinin hayatiyetine son verme hakkı, özellikle ağır veya tedavisi kabil olmayan hastalık durumlarına ya da belirli hayat veya hastalık evrelerine münhasır kılınamaz (kn. 210). Bu hakkın kullanımının belirli sebep ve saiklere özgülenmesi, intihara karar veren kişinin bu kararının sebep ve saikleriyle ilgili bir değerlendirme yapmayı ve bunların içerik itibarıyla önceden belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Oysa bu durum, Anayasanın özgürlük telakkisiyle bağdaşmamaktadır. Uygulamada da bu sebep ve saiklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti de oldukça güçtür ve böyle bir tespit girişimi de, Anayasanın dayandığı insan onuru ile bağdaşmaz ve şahsi sorumluluk bilinciyle kişiliğin serbestçe tekamülü amacına ters düşer. Bu bağlamda temel ölçüt, şahsi sorumluluk bilinciyle hareket eden kişinin genel değer tasavvurları, dinî vecibeler, hayat ve ölümle ilgili toplumsal telakkiler veya objektif bir bakış açısıyla makul addedilen mülahazat çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda serbestçe karar vermesidir (kn. 210).

Bu değerlendirmelerden sonra, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, Alman Anayasası, m. 1, f. 1 ile koruma altına alınan kişinin kendi geleceğini belirleme hakkının, sadece intihar etme hakkını değil, intiharına yardım etme hususunda başkalarından talepte bulunma ve hatta, bu yönde yapılan teklifi kabul etme özgürlüğünü de kapsadığını kabul etmektedir (kn. 212 vd.).

Almanya Federal Anayasa Mahkemesinin kabulüne göre, intihara karar vermiş olan kişi, bu kararının icrasında bir başkasından yardım da talep edebilir. Bu amaçla kişi, bir yakınından, hekimden veya sair sağlık görevlisinden ve hatta, intihar etmek isteyen kişilere yardım etmeyi iş edinmiş olan bir kişi veya kuruluştan da talepte bulunabilir (kn. 222).

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, sonuç itibarıyla Alman Ceza Kanunu, § 217'deki suç tanımının, kişinin kendi geleceğini belirleme hakkını kısıtladığı kabul edilmiştir (kn. 218 vd.).

Esasında Almanya Federal Anayasa Mahkemesi de, intihara yardımın kötüye kullanılabileceğini, kötüye kullanma tehlikesinin bulunduğunu kabul etmektedir (kn. 222).

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin **Çoşelav v. Türkiye** Kararına (1413/07, 9.10.2012) konu teşkil eden olayda; işlediği bir suçtan dolayı mahkum olduğu hapis cezasını çekmek üzere ceza infaz kurumunda bulunan Bilal, yatak çarşafıyla kendini asarak intihar eder. İntiharla sonuçlanan olay, şu şekilde cereyan eder:

Henüz 18 yaşını tamamlamadığı için Kars Cezaevinin çocuk koğuşuna konulan Bilal, 29.12.2003 tarihinde ceza infaz kurumunun avlusunda intihara teşebbüs eder. Ancak, infaz kurumu görevlilerinin müdahalesiyle, kurtarılır.

Keza, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, Alman Ceza Kanunu, § 217'deki suç tanımı ile güdülen amacın, meşru bir amaç olarak hayat hakkını korumak olduğu kabul etmektedir (kn. 227 vd.).

Avusturya Anayasa Mahkemesi de, 11 Aralık 2020 tarihli ve G 139/2019-71 sayılı Kararı ile Avusturya Ceza Kanununun intihara yönlendirme ve yardım fiillerini cezalandıran § 78 hükmünde yer alan “*oder ihm dazu Hilfe leistet,*” (veya intihar etmeye karar veren kişiye yardım ederse,) ibaresini benzer gerekçelerle, Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.

Buna karşılık, Avusturya Anayasa Mahkemesi, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi gibi, kişinin intihar etme yönünde karar vermesini bir “hak” olarak kabul etmekle birlikte, bir başkasının intihara yönlendirme fiilinin suç olma vasfını taşıdığına karar vermiştir.

Anayasa Mahkemelerinin bu kararlarına rağmen, her iki ülke ceza kanunlarında talep üzerine öldürme fiilleri, suç olarak tanımlanmaya devam etmektedir (Alman CK, §216; Avusturya CK, §77).

Ancak Almanya Federal Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında kişinin intihar etme yönünde karar vermesinin bir hak olarak kabul edilmesinin yanı sıra, “*Das Recht, sich selbst zu töten*” (“*kişinin kendi kendini öldürme hakkı*”) ibaresi kullanıldığı için (kn. 211, 212, bu karardan sonra Alman CK, § 216'daki “talep üzerine öldürme” suçuna ilişkin hükmün de anayasal dayanağının kalmadığı ileri sürülmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki, hayatiyet, insan onurunun temelini oluşturmaktadır. Hayatiyet olmadan, hayatiyete son verildikten sonra insan onurundan bahsetmek artık imkansızdır. Her ne kadar, kişinin hayatına son verme yönünde karar vermesi ve bu kararın icrası kişi onuruyla bağdaşmayan bir davranış değilse de, bu yönde verilen her kararın insan onurunun bir tezahürü olduğundan söz edilemez. İnsan onuru, kişiye otonom, muhtar, özgürlük içinde bir hayat sağlamaktadır. Kişinin onuru ile hayatiyetine son verme yönünde verdiği karar arasında bir bağlantı bulunabilir. Ancak bu bağlantı, hayatiyete son verme yönünde verilen kararın alelittak onurun bir tezahürü olmaktan ziyade, hayatiyetinin devamı sürecinde maruz kaldığı, kalmaya devam ettiği muamelenin insan onuruyla bağdaşmamasının kişiyi intihar yönünde karar almaya sevk etmesidir.

Esasında, kişinin hayatiyetine son verme yönünde verdiği karara hukuki değer atfetmek, kişinin şahsiyetini serbestçe tekamül ettirme amacıyla telif edilemez. Her ne kadar, kişinin şahsiyetini serbestçe tekamül ettirebilmesinin koşullarının ortadan kalkması, köleştirilmesinin, istismar edilmesinin, maruz bırakıldığı hayat şartlarının insan onuruyla bağdaşmaması, kişiyi intihar yönünde karar vermeye sevk edebilmekte ise de, bu yönde verilen karara hukuki geçerlilik tanınmaz. Aralarında bir ilişki kurulabilse de, insan onuru, intihar yönünde verilen karara hukuki geçerlilik sağlamaz.

Keza, intihar kararının “özgür iradeye” dayanabileceği yönündeki kabulün bilimsel gerçeklikle bir ilgisi bulunmamaktadır. İntihar kararının ancak mazur kabul edilebilecek bir sebebe dayanıp dayanmadığı konusunda bir değerlendirme yapılabilir. Şayet, kişinin intihar yönünde vermiş bulunduğu kararın, mazur sayılabilecek bir sebebe dayandığı değerlendiriliyorsa, bu kararın icrasına engel olmamak da mazur addedilebilir. Ancak, kişinin intiharına engel olmamak, hiçbir zaman hukuka uygun, haklı bir davranış olarak değerlendirilemez.

Kişileri intihara yönlendirmenin ve hatta, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi ile Avusturya Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararlarında kabul edilenin aksine, intihar etmeye karar vermiş olan bir kişiye bu kararının icrası bağlamında yardım edilmesinin bir “hak” olarak kabulünün hukuki temeli bulunmamaktadır.

Bilal, 19.1.2004 tarihinde aşırı dozda ilaç alarak tekrar intihara teşebbüs eder. Bu girişimi de sonuçsuz kalan Bilal, tedavi için hastaneye gönderilir ve bilahare, 28.1.2004 tarihinde, Erzurum Cezaevine nakledilir.

Çocuk koğuşuna konulan Bilal ile ilgili olarak mahkumlardan biri, 9.2.2004 tarihinde, ceza infaz kurumu yetkilisine garip davranışlarının olduğu, kendini asmaktan söz ettiği ve davranışlarının çocuk koğuşunda kaygılara neden olduğu bilgisini verir. Bu bilgi üzerine Bilal, fizikî görünümü de dikkate alınarak, yetişkinlerin bulunduğu koğuşa yerleştirilir.

Bilal, 27.2 ve 10.12.2004 tarihleri arasında ceza infaz kurumu yetkililerine 22 ayrı dilekçe vererek çeşitli taleplerde bulunur. Bu çerçevede, para kazanmak için çalışmak istediğini de bildirir.

Bilal, zaman içinde infaz kurumu yetkililerine sözlü olarak ilettiği çeşitli taleplerinin kabul edilmemesi üzerine kişilere ve eşyaya karşı saldırgan davranışlarda bulunur. Bu saldırgan davranışları dolayısıyla hücreye konulan Bilal, **17.12.2004 tarihinde** kafasını hücre duvarına çarparak kendini yaralar. Tedavisi yapılan Bilal tekrar hücreye konulur. Bilal, **aynı gün** bulunduğu hücrede yatak çarşafıyla kendini asarak intihar eder.

Bekir'in intihar ettiği bilgisi babasına 30.12.2004 tarihinde verilir ve cenazesi, 3.1.2005 tarihinde teslim edilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu olaya ilişkin kararında, pek çok kararında olduğu gibi, **devletin, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin hayatını kendilerine karşı da koruma, yani intihar girişimlerini önleme bakımından yükümlülüğünün olduğu**na vurgu yapmıştır (pn. 52 ilâ 54). Mahkeme, bu kararda olduğu gibi (pn. 70), söz konusu yükümlülüğün gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 2. maddesinde güvence altına alınan kişinin hayat hakkının ihlal edildiğine dair içtihatlarla bulunmuştur.⁶⁰⁷

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sorumluluk bağlamında AİHM, **kişinin intihar etme tehlikesinin bulunduğu**ntiharın gerçekleştiği tarih itibarıyla ilgili kamu görevlileri tarafından biliniyor olması veya bilinmesi gerektiği hususlarına vurgu yapmıştır. Yani gerçekleşen intihar olayı dolayısıyla sorumluluk için, ilgili kamu görevlilerinin en azından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarının bulunması gerekir.

⁶⁰⁷ Ayrıca bkz. *Keenan/Birleşik Krallık*, no. 27229/95, 3.4.2001; *Renolde/Fransa*, no. 5608/05, 16.10.2008. *Ketreb/Fransa*, no. 38447/09, 19.7.2012. *De Donder ve De Clippel/Belçika*, no. 8595/06, 6.12.2011. Buna karşılık, ceza infaz kurumunda bulunan bir hükümlünün intiharında devletin kişinin hayatını koruma yönündeki yükümlülüğünün ihlal edilmediği yönündeki karar için bkz. *Trubnikov/Rusya*, no. 49790/99, 5.7.2005.

Keza, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, askerlik görevini yapmakta olan ve ruhsal yönden çeşitli sağlık sorunları bulunan kişinin görev sırasındaki intiharı olayında devletin gerekli tedbirleri almamakla, Sözleşmenin 2. maddesiyle güvence altına alınan kişinin hayat hakkını ihlal ettiği yönünde içtihatla bulunmuştur: *Kılınç ve diğerleri/Türkiye*, no. 40145/98, 7.6.2005.

Buna göre gerçekleşen intihar olayı dolayısıyla sorumluluk için;

- a) Tutuklu, hükümlü veya asker kişinin intihar edebileceği yönünde somut bir tehlikenin mevcut olması,
- b) İlgili kamu görevlilerinin bu tehlikeyi bilmesi veya en azından bilebilecek durumda olması,
- c) İntihar girişiminin önüne geçebilecek, her somut olayın koşullarına göre makul tedbirlerin alınmamış olması,

gerekir.

Bu durumda ilgili kamu görevlilerinin hangi suç hükümlerine göre sorumluluğu cihetine gidilmesi gerektiği hususu, iç hukuk meselesidir.

Keza, Anayasa Mahkemesinin **9.6.2021** tarihli ve 2017/35564 BB sayılı kararı-na konu teşkil eden olayda, psikolojik ve hatta psikiyatrik sorunları bulunan hükümlü ceza infaz kurumunda bulunduğu odada kendini asarak intihar eder.

Bu olayda, yakınları, hükümlünün bu durumuna ilişkin olarak çeşitli sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş olan rapor ve belge örneklerini dayanak göstererek, intihara eğilimli kişilik sahibi olduğunu belirtirler ve ceza infaz kurumu yetkililerinden gerekli tedbirlerin alınması talebinde bulunurlar.

Bu olayda, hükümlünün ceza infaz kurumunda birkaç defa intihar girişiminde bulunması itibarıyla kendini öldürebileceği konusunda gerçek bir riskin bulunduğu kurum yetkililerince bilinmektedir (pn. 94). Ancak, infaz kurumu yetkilileri, buna rağmen hükümlünün odasında çamaşır ipi gibi intihar girişiminde kullanılabileceği eşyanın bulunmasını önlemek yönünde tedbir almazlar (pn. 96).

Anayasa Mahkemesi, daha önce verdiği değişik kararlardaki aşağıda iktibas edilen gerekçelere atıfta bulunarak, bu olayda hükümlünün hayat hakkının (maddi boyutunun) ihlal edildiğine karar vermiştir (pn. 97).

*“Devlet ... bir kişinin yaşamına yönelik gerçek ve yakın bir tehlikenin bulunduğu kamu makamlarınca bilindiği ya da **bilinmesi gerektiği durumlarda**, görevlileri aracılığıyla makul ölçüler çerçevesinde ve bu tehlikenin gerçekleşmesini önleyebilecek şekilde önlemler almalıdır.”* (kn. 92)⁶⁰⁸

“... ceza infaz kurumu yetkilileri, kontrolleri altındaki bir kişinin kendini öldürmesi konusunda gerçek bir risk olduğunu bildikleri ya da bilmeleri gereken durumlarda söz konusu riski ortadan kaldırmak için makul ölçüler çerçevesinde ve sahip oldukları yetkiler kapsamında almaları gereken tedbirleri almalıdırlar.” (kn. 93)^{609 610}

⁶⁰⁸ Ayrıca bkz. Anayasa Mahkemesi, 17.9.2013, BB 2012/752, kn. 53.

⁶⁰⁹ Anayasa Mahkemesinin **6.10.2021** tarihli ve 2018/32651 Bireysel Başvuru sayılı kararına konu teşkil eden olayda; ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan S, sabaha karşı kaldığı çoklu koğuşun havalandırmasına açılan kapı koluna kaşkolünü bağlayarak kendisini merdivenlerden aşağı bırakır ve intihar eder.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu değerlendirmeleri, bize sadece bu intihar olayından dolayı ilgili kamu görevlilerinin ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidilmesi gerektiği hususunda yol göstericilik özelliği taşımaktadır.

Bu durumda ceza infaz kurumu yetkilileri hakkında hangi suçtan dolayı yargılama yapılması gerektiği hususu Türk ceza hukuku uygulaması bakımından önemli bir sorun oluşturmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere, ilgili kamu görevlilerinin tutuklu, hükümlü veya asker kişi bakımından kanun gereği olarak **koruma ve gözetim (teminat) yükümlülüğü** bulunmaktadır.

Kişinin intihar girişimine muttali olunmasına rağmen, bu koruma ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen, yani intihar girişimini önlemeyen teminat yükümlüsünün, yukarıda açıklandığı üzere, bir başkasının **intiharına ihmalî davranışla yardım** etmekten dolayı TCK, m. 84 hükümlerine istinaden cezalandırılması gerekir.

Buna karşılık, koruma ve gözetim yükümlülüğünün gereklerinin yerine getirilmesinin ihmal edilmesinden yararlanılarak intihara teşebbüs edileceğinin öngörülmemesi durumunda, intihara teşebbüs veya intihar bakımından teminat yükümlüsünün ancak taksirinden söz edilebilir. Ancak, teminat yükümlüsünün bu ihmalden yararlanılarak intihara teşebbüs edilmesi veya intihar edilmesi halinde, teminat yükümlüsünün taksirle yaralamaya veya ölüme sebebiyet verme suçlarından dolayı sorumluluk cihetine gidilemez. Zira, kanuni tanımları itibarıyla söz konusu suçlara ilişkin hükümler intihar bağlamında uygulama kabiliyeti bulamaz.⁶¹¹

Ceza İnfaz Kurumunda psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen S ile ilgili olarak *uyum bozukluğu ve depresif bozukluk* teşhisi konmuş ve tedavisine başlanmıştır. Bu muayene sürecinde psikiyatri doktoru, S'nin "suisidal (intihar) düşüncelerinin bulunduğunu belirterek psikiyatri polikliniğine sevkini uygun görmüş, buna ilişkin hasta sevk kâğıdı düzenlemiştir." Ancak, S'nin psikiyatri doktoru tarafından muayeneyi istememesi üzerine, tedavisi sonlandırılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, bu olayda, ceza infaz kurumu yetkililerinin S'nin "*kendini öldürme riski olduğunu bilmedikleri söylenemez. ... S'nin kendisine zarar vermemesi için yetkililerin önleyici tedbirler alması gerektiği*" yönünde değerlendirmede bulunulmuştur (pn. 57).

Yüksek Mahkemenin değerlendirmesine göre, "*Ceza İnfaz Kurumu yetkililerinin S'nin sağlık durumunu takip ederek kontrol altında tutmaya çalışmaları ve bir hastanenin psikiyatri polikliniğine sevkini uygun görüldüğü şekilde gecikmeksizin sağlamaları, S'yi kendi iradesine bırakmadan kendisine zarar vermesini önlemek amacıyla koğuş ve havalandırma bölümünün belirli aralıklarla infaz ve koruma memurlarınca kontrol edilmesi, S'nin tutum ve davranışlarının takip edilmesi*" gerekirdi.

⁶¹⁰ Ayrıca bkz. Anayasa Mahkemesi, 17.9.2013, BB 2012/752, kn. 53; Anayasa Mahkemesi, 20.5.2015, BB 2013/6979, kn. 72.

⁶¹¹ Ancak, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aşağıya iktibas edilen kararında bu durumda **taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan** dolayı sorumluluk yoluna gidilmesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur:

"*Polis memuru olarak görev yapan sanığın, son 5-6 yıldır depresyon hastası eşi ile eşinin babasının köyde bulunan evine gittikleri, sanığın silahını yanında dolu şarjörü ile birlikte oda-*

Ancak, teminat yükümlüsü olan kamu görevlisinin bu koruma ve gözetim görevinin bilincinde olmasına rağmen, bunun gereklerini yerine getirmemesinden istifade edilerek intihara teşebbüs veya intihar edilmesi halinde, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan dolayı ceza hukuku sorumluluğu cihetine gitmek gerekir. Bu durumda kamu görevlisi teminat yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmeyi kasten ihmal etmiş ise de, bu ihmalden yararlanılarak koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişinin intihara teşebbüs edeceğini veya intihar edeceğini öngörmemiştir. Koruma ve gözetim altında bulunan kişinin intihara teşebbüs veya intihar etmesi, ihmali davranışla işlenen bu görevi kötüye kullanma suçu bakımından bir objektif cezalandırılabilme şartı mahiyeti taşımaktadır.⁶¹²

Anayasa Mahkemesinin **8.3.2018** tarihli ve 2014/15959 bireysel başvuru sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; anne A, vücudundaki gelişme ve değişikliklerden şüphelenmesi üzerine, 9.4.1996 doğumlu kızı F'yi 27.7.2013 tarihinde doktora götürerek muayene ettirir. Bu muayenede F'nin yaklaşık yedi aylık hamile olduğu anlaşılır. F'nin, 2012 yılının Kasım ayından beri kendisinden birkaç yaş büyük olan B ile arkadaş olduklarını ve bu arkadaşlık sürecinde müteaddit defa cinsel ilişkiye girdiklerini anne ve babasına anlatması üzerine, ailesinden kişiler, B ve ailesinden sair kişilerle görüşerek bu duruma bir çözüm bulmaya çalışırlar. Ancak, bu arada F, 28.7.2013 tarihinde intihar eder.

lardan birinde koltuğun üzerine bıraktığı, ev halkı balkonda ve bahçede bulunurken ölenin eve girip eşinin koltuk üzerinde bulunan silahına şarjörü takıp başına bir el ateş ederek öldüğü olayda; sanığın ölü muayenesi sırasında verdiği ifadesinde; eşinin depresyon hastası olduğunu, olay günü eşinin rahatsızlığı nedeniyle psikiyatri bölümünde muayene olduğunu, doktorunun yatış önerdiğini ancak eşinin kabul etmemesi üzerine eşinin babasının köyde bulunan evine gittiklerini, eşinin daha önce yine kendi silahı ile iki kez intihara teşebbüs ettiğini, bu nedenle silahı eşinden sakladığını ve mermileri cebinde taşıdığını, hastaneden geldikten sonra cebinde taşıdığı mermileri şarjöre yerleştirerek silahı ve şarjörünü ayrı vaziyette odalardan birindeki koltuğun üzerine koyduğunu, eşinin şarjörün silaha nasıl takıldığını bildiğini beyan ettiği dikkate alındığında; sanığın eşinin hastalığının aktif döneminde intihara teşebbüs edebileceğini öngörebileceği ve eşinin silah kullanmayı bildiği halde dolu şarjör ve silahı herkesin kolayca ulaşabileceği bir yere bırakarak bilinçli taksirle hareket ettiği anlaşılmakta; sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasında isabetsizlik görülmüştür; Yargıtay 12. CD, **16.5.2014**, E. 2013/21595, K. 2014/12058.

Bu karar bağlamında belirtilmek gerekir ki, söz konusu olayda intihar edenin eşi hakkında, TCK, m. 22, f. 6'da düzenlenen cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep hükmünün uygulanmamış olması, önemli bir eksikliktir.

⁶¹² Yargıtay 9. Ceza Dairesi, “fiziksel ve ruhsal durumu itibarıyla kendi hayat bütünlüğü bakımından tehlike arz ettiğine dair belirtiler bulunan ...'un yakalama işlemi hakkında derhal Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılmadığı gibi yakınlarına da haber verilmediği ayrıca tek başına kendisine zarar verebilecek eşyalardan arındırılmadan ve gerekli tedbirleri almadan avukat bekleme odasında tutmak suretiyle mevzuattaki emredici hükümleri yerine getirmekte ihmal ve gecikme gösterildiği ve bu şekilde ...'un avukat bekleme odasının demir korkuluklarına kemeri ile asarak intihar etmesine neden olunduğu iddia ve kabul edilen somut olayda” ilk derece mahkemesinin, ilgili kamu görevlisinin ihmalinin **ihmalî davranışla görevi kötüye kullanma suçunu** oluşturduğu yönündeki kabulünü hukuka uygun bulmuştur; Yargıtay 9. CD, **30.6.2020**, E. 2020/329, K. 2020/749.

A, B'nin tutum ve davranışlarıyla kızı F'yi intihara yönlendirdiğini iddia ederek, hakkında suç duyurusunda bulunur. Soruşturma kapsamında yapılan DNA testinde, F'nin hamile kaldığı ceninin babasının B olduğu anlaşılır.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; F hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, F'nin cinsel birliktelik yaşadığı tarihlerde on beş yaşından büyük ve B ile cinsel ilişkisinin rızaya dayalı olması karşısında, cinsel istismar suçunun oluşmadığı; reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bakımından ise şikayette bulunulmadığı için A hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının mümkün olmadığı; A'nın F'yi intihara yönlendirme suçunu işlediği yönündeki iddianın dayandığı somut ve objektif delil bulunmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Bu olayda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesiyle hak ihlalinde bulunulduğu iddiasıyla yapılan bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesinin verdiği kararda, sorun sadece F'nin anne ve babasının şikayet hakkını haiz olup olmadığı bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Bu olay bağlamında maddi ceza hukuku bakımından değerlendirilmesi gereken husus, F'nin intiharı dolayısıyla B'nin ceza hukuku bakımından sorumluluğu cihetine gidilip gidilemeyeceğidir.

Nedensellik bağı, fail ve icra ettiği fiil ile gerçekleşen netice arasındaki objektif ilişkiyi ifade etmektedir. Failin fiili ile gerçekleşen netice arasındaki sebep - sonuç ilişkisini ifade eden illiyet bağı, tamamen doğal bir olgudur, tabii bir vakiydir. Ancak bir olayda gerçekleşen neticeden failin sorumlu tutulabilmesi için doğal bir olgu olan nedensellik bağının kurulması yeterli olmayabilir. Bazı durumlarda gerçekleşen neticeden failin sorumlu tutulabilmesi için, nedensellik bağının varlığının yanı sıra, bu neticenin faile objektif olarak isnat edilebilir olması gerekir. Tamamen doğal bir olgu olan nedensellik bağına nazaran, objektif isnadiyet bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.

Söz konusu olayda, mağdur F'nin intiharı ile, ölüm öncesinde yaşadığı olaylar arasında doğal bir olgu olarak nedensellik ilişkisi kurulması mümkündür. Ancak, her ne kadar F yaşadığı olayların etkisiyle intihar etme yönünde bir tercihte bulunmuş ise de, intihar etmek suretiyle gerçekleşen ölüm neticesini A'ya veya başka herhangi birine objektif olarak isnat etmek, hukuken mümkün değildir.

Yargıtay, mülga 765 s. TCK'nin yürürlükte olduğu dönemdeki içtihatlarında sorunu nedensellik bağından hareketle bir çözüme kavuşturma eğiliminde idi ve bu tür olaylarda kişinin intiharı ile intihar öncesinde yaşadığı olaylar arasında nedensellik bağının bulunmadığı gerekçesiyle ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidilmemesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştu.⁶¹³

⁶¹³ **Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 12.5.1980** tarihli ve 1-151/206 sayılı Kararına (YKD, Eylül 1980, sh. 1279 vd.) konu teşkil eden olayda, S ile sekiz senedir evli olup, üç çocuğu bulunan Feruzan, kayınvalidesi ve kayınpederi ile aynı evde oturur; bu şahıslarla arasında geçimsizlik bulunduğu gibi, başka bir kadınla ilişkisinden şüphelendiği S ile aralarında da geçimsizlik bulunur.

Anayasa Mahkemesinin kararına konu teşkil eden olayda şayet hamile kalan F, B'ye kendisiyle evlenme iradesini açıklamış; B'nin bu teklifi kabul etmemesi karşısında intihar edeceğini söylemiş; buna rağmen B, F'nin bu intihar düşüncesinin gerçekleşmemesi için gereken girişimlerde bulunmamış ve neticede F intihar etmiş olsaydı, B'yi ceza hukuku bakımından sorumlu tutmak gerekirdi. Bu durumda B'yi TCK, m. 84 düzenlemesi karşısında, **intihar girişimini önlememek suretiyle intihara yardım**da bulunmaktan dolayı sorumlu tutmak gerekirdi⁶¹⁴.

V. TCK'da **ışkence** suçu ile bağlantılı olarak da, teminat yükümlüsü kamu görevlisinin ceza sorumluluğuna ilişkin özel bir hükme yer verilmiştir: ışkence suçunun *“ihmalî davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.”* (TCK, m. 94, f. 5). Madde gerekçesinde bu hükme ilişkin olarak şu açıklamalar yer almaktadır:

*“İşkence suçu, çoğu zaman, amir mevkiindeki kamu görevlilerinin zımni muvafakatiyle gerçekleştirilmektedir. Başka bir deyişle, amir konumundaki kamu görevlisi, kendi gözetim yükümlülüğü altında yürütülmekte olan bir soruşturma işlemi sırasında kişilere ışkence yapıldığını öngörmesine rağmen bu konuda gerekli müdahalede bulunmamak suretiyle ışkence yapılmasına zımnen rıza göstermiş olabilir. Maddenin beşinci fıkrasına göre; bu gibi durumlarda, amir konumundaki kamu görevlisi, **ihmalî davranışla ışkence suçunu** işlemiş kabul edilecek ve bu nedenle cezasında indirim yapılmaksızın sorumlu tutulacaktır.”*^{615 616}

VI. **Terk** suçu da TCK'da bir **görünüşte ihmalî suç** olarak tanımlanmıştır (m. 97). Çünkü, bu suç, madde gerekçesinde açıkça ifade edildiği gibi,⁶¹⁷ ancak bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan, yani teminat yükümlüsü olan

Feruzan, zaman zaman kocasının kendisine şiddet uyguladığını ve ayrılmak istediğini babasına anlatır, ancak babasının boşanmasına razı olmaması nedeniyle tekrar eşinin yanına döner. Aile içinde geçimsizlik yaşamaya devam eden Feruzan, arkadaşı hemşire Şükran'a zaman zaman telefon ederek problemlerini anlatır. Aile içindeki geçimsizliklerin artması üzerine Feruzan bu defa, dokuz aylık çocuğunu yanına alıp, bir hemşehrisinin evine gider; ancak aile dostlarının tavsiyeleri uyarınca tekrar kocasının yanına döner. Buna rağmen kocasıyla arasında geçimsizlik devam eder ve tekrar tekrar kocasının şiddetine maruz kalır. Bu muameleler üzerine bunalım geçiren Feruzan, odasına kapanarak asmak suretiyle kendisini öldürür.

Yargıtay bu olayda S'nin fiilleri ile Feruzan'ın intiharı arasında nedensellik bağının bulunmadığı ve bu intihar dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidilemeyeceği yönünde içtihatla bulunmuştu.

⁶¹⁴ <https://izzetozgenc.com/data/contents/hukumlunun-ceza-infaz-kurumunda-intihari-dolayisiyla-ceza-hukuku-sorumlulugu.pdf> (Yayına giriş tarihi: 20.9.2021; Erişim tarihi: 18.10.2022).

⁶¹⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 500 vd.

⁶¹⁶ Bkz. Yargıtay 8. CD, **5.4.2017**, E. 2016/5680, K. 2017/3721; Yargıtay 8. CD, **6.3.2014**, E. 2013/7707, K. 2014/5504.

⁶¹⁷ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 646 vd.

(garantör) tarafından işlenebilir.⁶¹⁸ Kişinin bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan ve kendini idare edemeyecek durumda olan birisini terk etmesi, yani bu kişiye karşı bakım ve gözetim yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmemesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.^{619 620}

⁶¹⁸ Ancak, belirtmek gerekir ki, Yargıtay 4. Ceza Dairesi, gerçek ve görünüşte ihmalî suç ayrımında **neticeyi** esas alan doktriner görüşlerden etkilenecek, terk suçunun **gerçek ihmalî suç** olduğunu kabul etmektedir:

“*Türk Ceza Kanununun 97. maddesinde düzenlenen terk suçunun birinci fıkrasında, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi hâline terk etmek suç olarak tanımlanmış, terk olgusu bağımsız bir suç olarak kabul edilmiştir. Suçun mağduru, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kimse, faili ise, bu kimseler üzerinde kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan koruma ve gözetim yükümlülüğü yüklenen kişilerdir. Yükümlülüğün kanundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit, 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere ilgili kanunlardan yararlanılırken, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğün belirlenmesinde, sözleşmenin kapsamı ve içeriği esas alınır. Sözleşme şekle bağlı değildir. Yazılı ya da sözlü olabileceği gibi gönüllü üstlenme şeklinde fiili durumdan da kaynaklanabilir. Hekim, hemşire, hasta bakıcı, çocuk/bebek bakıcısı, hizmetçi, gezi rehberi, öğretmen gibi kişiler, sözleşmenin içeriğine göre koruma ve gözetim yükümlüsü sayılabilir.*

Bu suçla korunan hukuki değer, insanın yaşama ve vücut bütünlüğü hakkının yanı sıra koruma ve gözetim yükümlülüğü olan kişilerin bu görevlerini yerine getirmelerinin sağlanması ve bu sayede ortaya çıkacak sosyal fayda düşüncesidir.

Suçun maddi unsuru yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdurun “kendi haline terk edilmesidir”. Suç bağlamında “kendi haline terk”, failin, mağdurla olan fiili ilişkisini geçici ya da sürekli şekilde kesmesi ve mağduru egemenlik alanının dışına çıkarması, bu bağlamda kendi haline bırakmasıdır. Bu suç “kendi haline terk” gerçekleştiği anda tamamlanır. Terk süresi uzun veya kısa olabilir. Burada önem taşıyan husus, terk süresinin mağdur için tehlike yaratma hususunda yeterli olup olmadığıdır. Kişinin kendi haline terk edilmesi, koruma ve gözetim altında bulunan, bu yükümlülüğü üstlenmiş olan kişi tarafından herhangi bir yerde korumadan yoksun hale getirilmesidir. Terk fiilinin, fail dışında, koruma ve gözetim yükümlülüğünü üstlenebilecek durumda olan ve bu iradeyi taşıyan kişilerin inisiyatif kullanabilecekleri biçimde ve ortamda gerçekleştirilmesi halinde bu suç oluşmaz.

Suçun oluşumu için, failin mağduru, koruma ve gözetim yükümlülüğü üstlenebilecek durumdaki bir kişi veya kurumun kontrolüne bırakmaksızın “mağduru kendi haline terk” fiilini gerçekleştirmesi veya terk anı itibarıyla bu yükümlülüklerin kim tarafından taşınacağına belirsiz olması gerekir.

Terk suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Faildeki saikin önemi yoktur. Fail yaşı, hastalığı dolayısıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle yasa, sözleşme, doğal bağlılık ilişkisi veya fiili bir nedenden dolayı koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişiyi terk etme bilinç ve iradesiyle hareket etmelidir. Başka bir deyişle fail, “kendi haline terk” eyleminden doğacak neticeyi bilmeli ve istemelidir.

*Mağdurun kendi haline terk edilmesi, icrai ya da ihmalî davranışla gerçekleştirilebilir. Terk suçu, **gerçek ihmalî suçtur** ve kanunda tarif edilen belli bir emredici davranışın (terk etme) kasten yerine getirilmemesi ile oluşur.”: Yargıtay 4. CD, **4.11.2019**, E. 2015/21076, K. 2019/17077; Yargıtay 4. CD, **12.5.2016**, E. 2016/5394, K. 2016/9879; Yargıtay 4. CD, **25.12.2015**, E. 2014/34362, K. 2015/40853.*

⁶¹⁹ Yargıtay 4. Ceza Dairesinin **7.7.2015** tarihli ve E. 2014/11850, K. 2015/33091 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; bakıma muhtaç ve hasta olan ve bu nedenle çocukları tarafından nöbetleşe bakılan 86 yaşındaki M, bakım dönemi biten gelini H tarafından, M’nin diğer oğlu

Terk suçunun ihmalî davranışla işlenmesi halinde, teminat yükümlüsü (garantör), terk edilen ve bu suretle bakımsız ve gözetimsiz kalan kişinin örneğin ölebileceği öngörür. Terk edilenin ölmesi halinde, terk eden teminat yükümlüsünün (garantörün) ne suretle sorumlu tutulacağı, kast veya taksirine bağlı olarak belirlenecektir. Terk eden, terk edilen kişinin ölebileceğini veya sağlığının bozulabileceğini öngörmesine rağmen, “ölürse de ölsün” veya “hastalanırsa da hastalansın” düşüncesiyle hareket etmiş ve bu muhtemel neticeler bakımından kayıtsız kalmış ise, artık terk suçundan dolayı değil, ihmalî davranışla işlediği kasten (olası kastla) öldürme (TCK, m. 83) veya yaralama (TCK, m. 88) suçundan dolayı sorumlu tutulması gerekir.^{621 622} Buna karşılık, terk eden, terk edilen kişinin

R'nin evine getirilir. R, evde olmasına rağmen, ışıkları söndürüp evde yokmuş izlenimi oluşturmaya çalışır ve kapıyı açmaz. Bunun üzerine H, M'yi R'nin ev kapısı önünde komşudan temin ettiği sandalyeye oturatarak, olay yerinden ayrılır. R ise, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç olan annesi M'yi gece boyunca evine almaz. M, gecenin ilerleyen saatlerinde durumu fark eden komşuları tarafından eve alınır.

Bu olayda İlk Derece Mahkemesi, R'nin **terk** suçunu işlediğini kabul ederek, hakkında TCK, m. 97, f. 1 hükmüne istinaden mahkûmiyet hükmü kurmuştur. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, R'nin sorumluluğu bakımından doğru bulduğumuz bu mahkûmiyet hükmünün onanmasına karar vermiştir.

Söz konusu kararda, gelin H'nin ceza hukuku sorumluluğunun tartışılmaması, önemli bir eksiklik. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türk Medeni Kanunu, kişiye kayın hısımları ile ilgili olarak bakım ve gözetim yükümlülüğü yüklememektedir. Bu itibarla H, M ile ilgili olarak **kayın hısımlığı dolayısıyla teminat yükümlüsü değildir**. Ancak, kişi, kayın hısımlığı dolayısıyla teminat yükümlüsü değilse de, **sosyal ilişkilerin gereği olarak kayın hısımlarının bakım ve gözetimini üstlenmiş olabilir**. Sosyal ilişkilerden kaynaklı olarak da olsa, bakıma muhtaç bir kişinin bakım ve gözetiminin üstlenilmesi, üstlenen kişiyi **teminat yükümlüsü** kılar. Karara konu teşkil eden olayda H, M'nin bakım ve gözetimini üstlenerek teminat yükümlüsü olmuştur.

Dikkat edilmelidir ki, H, M'yi R'ye teslim etmemiş, R'nin eve kabul edeceği beklentisi ile evinin kapısı önünde kendi haline bırakmıştır. Bu ümit ve beklenti, H'nin kusurluluğu bağlamında ve dolayısıyla, ceza hukuku sorumluluğunun belirlenmesinde dikkate alınabilecek bir husus olmakla birlikte, terk suçu bakımından kastı ortadan kaldırmaz. Terk suçunun **soyut tehlike suçu** özelliği taşıdığını da göz önünde bulundurmak gerekir.

⁶²⁰ Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 4.11.2019 tarihli ve E. 2015/21076, K. 2019/17077 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; aralarında evlilik birliği bulunmayan ve her ikisi de alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olan A ve B'nin bir çocukları dünyaya gelir. Çocuk (Ç), hastane dışı bir ortamda dünyaya gelir. Anne B, doğumdan kısa bir süre sonra, Ç'yi bir hastanenin acil servisine bırakır.

Bu olayda İlk Derece Mahkemesi, B'nin **terk** suçunu işlediğini kabul ederek, hakkında TCK, m. 97, f. 1 hükmüne istinaden mahkûmiyet hükmü kurmuştur. Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise, suçun “*manevi unsurunun gerçekleşmediği*” gerekçesiyle, bu mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Bu olayda da bir **soyut tehlike suçu** olan terk suçu işlenmiştir. Söz konusu suçun maddi ve manevi unsurları oluşmuştur. Ancak, anne ve babanın her ikisinin de alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olması, sadece bu suç nedeniyle kusurlulukları bağlamında dikkate alınmalıdır.

⁶²¹ Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 3.2.2020 tarihli ve E. 2019/2477, K. 2020/258 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; S, bir TV kanalındaki ilanlar aracılığı ile tanıştığı M ile küçük yaştaki oğlu O'yu bir kış gününde arabasıyla ormanlık alana getirerek, burada O'nun gözü önünde M ile cinsel ilişkiye girer; bilahare de M'yi darp eder. M, maruz kaldığı bu darp fiilinin etkisiyle ölür. S, ayrıca M'nin üzerinde bulunan yaklaşık 6.000 TL para ile 5 adet altın bileziği alır; keza, küçük yaştaki

O'yu, yerleşim yerlerinden uzakta bulunan ormanlık alanda bırakır. Ormanda tek başına donmak üzere olan O, tesadüfen olay yerine gelen avcılar tarafından görülerek hemen hastaneye götürülür.

İlk Derece Mahkemesi, bu olayda S'nin, M'ye karşı kasten öldürme ve yağma suçlarını işlediğini kabul ederek bu suçlardan dolayı ayrı ayrı mahkûmiyet hükmü kurmuştur. Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu mahkûmiyet hükümlerinin onanmasına karar vermiştir.

Keza, İlk Derece Mahkemesi, O'yu ormanda tek başına bırakması bağlamında S'nin **teşebbüs** aşamasında kalmış **ihmalî davranışla kasten öldürme suçunu** işlediğini kabul ederek, hakkında mahkûmiyet hükmü kurmuştur. Ancak, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, S'nin bu fiilinin **ihmalî davranışla kasten yaralama suçunu** oluşturduğu ve hakkında TCK, m. 86, f. 1, f. 3 (bent b); m. 87, f. 1 (bent d) ve m. 88 hükümleri uyarınca cezalandırılması gerektiği gerekçeyle, İlk Derece Mahkemesinin bu mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Karara konu teşkil eden olay bağlamında çözümlenmesi gereken sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:

- 1) S'nin M ile küçük yaştaki oğlu O'nun gözleri önünde cinsel ilişkiye girmesi, ceza hukuku sorumluluğunu gerektirir mi?
- 2) S'nin M'yi öldürmesi dolayısıyla TCK'nın hangi hükümlerine istinaden cezalandırılması yoluna gidilebilir?
- 3) S'nin, M'nin üzerindeki 6.000 TL ile ziynet eşyasını alması fiili dolayısıyla, TCK'nın hangi hükümlerine istinaden ceza sorumluluğu yoluna gidilebilir?
- 4) S'nin O'yu ormanda yalnız bırakması fiili dolayısıyla TCK'nın hangi hükümlerine istinaden ceza sorumluluğu yoluna gidilebilir?

Hukuki değerlendirmelerimiz:

1. sorun: S'nin M ile küçük yaştaki oğlu O'nun gözleri önünde cinsel ilişkiye girmesi, TCK, m. 103'de tanımlanan çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturur. 15 yaşından küçük olan çocuğa karşı, fiziksel temas olsun veya olmasın, cinsel arzuları tatmine yönelik her türlü davranış, **çocuğun cinsel istismarı** suçunu oluşturur.

O'nun 15 yaşından büyük çocuk olması halinde, söz konusu fiil, **cinsel taciz** suçunu oluşturur. Bu durumda temel cezayı TCK, m. 105, f. 1 ikinci cümle hükmüne istinaden belirlemek gerekir. Keza, suçun teşhir suretiyle işlenmiş olması dolayısıyla, TCK, m. 105, f. 2 (bent e) hükmüne istinaden cezayı artırmak gerekir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Cinsel Suçlar, Türk Ceza Kanununun Cinsel Suçlara İlişkin Düzenlemelerinin Dayandığı Felsefi Temel, Cinsel Suçlara İlişkin Kanun Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlar*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXIV, sayı 1, Ocak 2020, sh. 257 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: *Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bakımından İlgilinin Rızasının Ceza Hukuku Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXIV, sayı 2, Nisan 2020, sh. 251 vd.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararında bu hususa temas edilmemiş olması, önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir.

2 ve 3. Sorun: S'nin M'nin ölümü dolayısıyla S'nin ceza hukuku sorumluluğunu kastına göre belirlemek gerekir:

S, şayet M'yi yaralamak kastıyla darp etmişse, **neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama** suçundan dolayı sorumlu tutulması gerekir.

S, şayet M'yi öldürmek kastıyla darp etmişse, **kasten öldürme** suçundan dolayı sorumlu tutulması gerekir.

S, şayet üzerindeki para ve ziynet eşyasını almak için M'yi öldürmüş ise, **bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme** suçundan TCK, m. 82, f. 1, bent h hükmüne istinaden cezalandırılması gerekir. Bu durumda, M öldükten sonra üzerindeki para ve ziynet eşyasını aldığı için S'nin ayrıca **hırsızlık** suçundan dolayı cezalandırılması gerekir.

Ancak Yargıtay uygulamamız, bu durumda hırsızlık değil, **yağma** suçunun oluştuğunu kabul etmektedir.

ölebileceğini veya sağlığının bozulabileceğini öngörmesine rağmen, ölmesini ve sağlığının bozulmasını istememiş, bakım ve gözetiminin bir başkası tarafından yerine getirileceğine ümit bağlamış ise, meydana gelen ölüm neticesinden veya sağlığının bozulmasından bilinçli taksiri dolayısıyla sorumlu tutulmalıdır.

VII. Buna karşılık, teminat yükümlülüğün ihlalini ceza yaptırımına bağlayan bu düzenlemelerden farklı olarak, TCK, m. 98’de tanımlanan yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunda failin mağdur bakımından teminat yükümlülüğü bulunmamaktadır.⁶²³

Kanun, “yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan” kişilerle⁶²⁴ ilgili olarak, bu duruma muttali olan kişilere yardım veya bildirim yükümlülüğü yüklemektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu duruma muttali olan kişinin yardım veya bildirim yükümlülüğü bulunmakla birlikte, teminat yükümlülüğü mevcut değildir.⁶²⁵ Zira,

S’nin, üzerindeki para ve sair ziynet eşyasını almaya M öldükten sonra karar vermiş olması halinde ise, **hırsızlık** suçundan dolayı sorumlu tutulması gerekir.

4. sorun: S, O’yu ormanda yalnız bırakmıştır. TCK, m. 97’de tanımlanan terk suçu, ancak koruma ve gözetim yükümlüsü, yani **teminat yükümlüsü** (garantör) tarafından işlenebilen bir suçtur. Normal şartlarda S’nin O’ya karşı koruma ve gözetim yükümlülüğü mevcut değildir. Ancak, S, terk fiili öncesinde annesi ve velisi M’yi öldürmesi (**ön gelen fiil**) dolayısıyla, O’ya karşı teminat yükümlülüğü altına girmiştir. Bu nedenle, O’yu ormanda yalnız bırakmak suretiyle **terk** suçunu işlemiştir. Ancak bu terk sonucunda O’nun sağlığının bozulmuş olması dolayısıyla S’nin TCK, m. 97, f. 1 hükmüne istinaden değil, f. 2 hükmüne istinaden cezalandırılması gerekmektedir. Bu durumda, terkin sonucuna göre ceza hukuku sorumluluğu cihetine gitmek gerekecektir. Belirtmek gerekir ki, küçük yaştaki bir çocuğu kış gününde ormanda terk eden kişi, bunun sonucunda çocuğun sağlığının bozulabileceğini ve hatta ölebileceğini öngörür. Başka bir ifadeyle, S, bu terk sonucunda gerçekleşen O’nun sağlığının bozulması neticesi ile ilgili olarak **olası kastla** hareket etmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararında S’nin ceza hukuku sorumluluğuna ilişkin bu teorik izahlar yapılmadan, sorunun, küçük yaştaki çocuğu (O’yu) ormanda tek başına bırakması bağlamında S’nin **teşebbüs** aşamasında kalmış **ihmalî davranışla kasten öldürme** suçundan dolayı mı yoksa **ihmalî davranışla kasten yaralama** suçundan dolayı mı sorumlu tutulması gerektiği hususuna inhisar ettirilmesi, önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir.

⁶²² TCK, m. 97 gerekçesi (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 504 vd.). Ayrıca bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, 7. bası, sh. 153; TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, Ceza Özel Hukuku, 18. bası, sh. 345. Ancak belirtmek gerekir ki, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, **kasten öldürme suçunun ihmalî davranışla işlenmesi halinde, olası kasta ilişkin hükümlerin (TCK, m. 21, f. 2) uygulanamayacağı** yönünde içtihatla bulunmuştur: Yargıtay 1. CD, **14.3.2018**, E. 2016/3056, K. 2018/1201. Bu içtihadın doğru olmadığını belirtmek gerekir. Dikkat edilmelidir ki, kasten öldürme suçunun ihmalî davranışla işlenmesi halinde, cezada indirim yapıp yapmama konusundan hâkime takdir yetkisi tanınmıştır (TCK, m. 83, f. 3).

⁶²³ Bkz. Yargıtay CGK, **17.1.2017**, E. 2014/1-252, K. 2017/5.

⁶²⁴ “Kendini idare edemeyecek durumda olma hali ile kastedilen, mağdurun, bir başkasının yardımı olmadığı takdirde, hayatına, sağlığına veya vücut bütünlüğüne yönelik ağır bir tehlikenin mevcudiyeti olması şeklinde anlaşılmalıdır.”: Yargıtay 4. CD, **18.1.2016**, E. 2015/27008, K. 2016/615.

⁶²⁵ “Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu ile korunmak istenen hukuki değer, kişilerin yaşam hakkı ve vücut bütünlüğünün korunmasıdır. Ayrıca bu suçla, top-

teminat yükümlülüğü, ön gelen fiil hariç olmak üzere, failin hukuki statüsünden veya fail ile mağdur arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanmaktadır. Oysa, TCK, m. 98'deki suç tanımıyla, olaya ve duruma muttali olan herkes bakımından yardım veya bildirim yükümlülüğü ihdas edilmiştir. Başka bir ifadeyle, söz konusu suçun faili **herkes** olabilir.

Söz konusu suç, bir *soyut tehlike suçudur*. Bu yardım veya bildirim bilahare bir başkası tarafından yapılmış olması halinde de, yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi bakımından suç oluşmaktadır.

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihmalinden dolayı sorumluluk için, kendini idare edemeyecek durumda olan kişiye yardım etme veya durumu hakkında ilgili mercilere bilgi vermek imkân ve iktidarına sahip olmak gerekir.⁶²⁶

Söz konusu suç tanımıyla, örneğin bir “kaza” dolayısıyla meydana gelen yaralanmalarda, **kazaya karışmamış** olmakla birlikte, kazada bir kişinin veya kişilerin kendi başının çaresine bakamayacak şekilde yaralandığına muttali olan sair kişiler bakımından yardım veya bildirim yükümlülüğü ihdas edilmiştir.^{627 628}

lumda birlikte yaşayan bireylerin, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye “ahlaki ve sosyal bir ödev” olan yardım ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri amaçlanmış ve toplumsal dayanışmanın bu suretle yaşatılması hedeflenmiştir.

Yardım veya bildirim yükümlülüğü medeni toplumlarda toplumsal ve sosyal hayatın gerekliliklerinden kaynaklanmaktadır. Bireylerin, zayıfları koruma ve yardım etme görevinin bulunduğu kabul edilir. Ayrıca bu yükümlülüklerin ahlaki bir yönü de vardır. Bu düzenleme ile bireylerin yardıma muhtaç olduğu durumlarda, diğer kişiler bakımından yardımda bulunma ya da en azından ilgili makamlara durumu haber verme mecburiyeti getirilip, yardıma hukuki bir nitelik kazandırılarak, aykırı davranışlar cezai yaptırıma bağlanmıştır.”: Yargıtay 4. CD, 18.1.2016, E. 2015/27008, K. 2016/615.

⁶²⁶ Yargıtay 4. CD, 18.1.2016, E. 2015/27008, K. 2016/615; TEZCAN/ERDEM ÖNOK, Ceza Özel Hukuku, 18. bası, sh. 354.

⁶²⁷ Bu yükümlülük bağlamında önce yardımın mı yoksa bildirimin mi yapılması gerektiği, bir sorun olarak ortaya çıkabilir. Yargıtay, bir kararında öncelikle yapılması gerekenin yardım olduğu, “yardımın yeterli olmayacağı” hallerde ise bildirimde bulunulması gerektiği değerlendirmesinde bulunulmuştur: Yargıtay 4. CD, 18.1.2016, E. 2015/27008, K. 2016/615. Ayrıca bkz. TEZCAN/ERDEM ÖNOK, Ceza Özel Hukuku, 18. bası, sh. 357.

Kanaatimizce her somut olayın özelliğine göre bir yol izlemek gerekir. Bazı olaylarda, sadece bildirimde bulunmak; bazı olaylarda ise, sadece yardım etmek yeterli olabilir. Keza bazı olaylarda, yardımın yanı sıra bildirimde de bulunmak gerekebilir.

⁶²⁸ Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 25.6.2015 tarihli ve E. 2014/14361, K. 2015/11881 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, A, sevk ve idaresindeki araçla ve yanında B olduğu halde gece saat 02.00 sıralarında seyrederken, önünde motosikletiyle seyir halinde olan C'ye çarpar. Alkollü olan A, kazanın hemen akabinde olay yerinden uzaklaşır. Olay yerinden geçmekte olan kolluk görevlilerince fark edilen C, tedavi için hastaneye kaldırılır.

Bu olay dolayısıyla açılan kamu davasında, İlk Derece Mahkemesi, A hakkında,

a) 170 promil alkollü olarak araç kullandığı için, **trafik güvenliğini tehlikeye sokma** suçundan (TCK, m. 179),

b) C'ye çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği için, **taksirle yaralamaya sebebiyet verme** suçundan (TCK, m. 89), ve,

Bir trafik kazasında kendini idare edemeyecek şekilde yaralanan kişi ile ilgili olarak yardım veya bildirimde bulunmayan kişi şayet teminat yükümlüsü (garantör) ise, duruma göre TCK, m. 97 veya 83 hükümlerine göre cezalandırılır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, karayolu trafik düzenine ilişkin kurallara aykırı araç kullanarak karıştığı trafik kazasında bir başkasının yaralanmasına sebebiyet veren sürücü, yaralanan kişinin tedavi edilmesini sağlamakla yükümlü kılınmıştır (TCK, m. 83, f. 2, bent b). Yaralanan kişinin tedavi edilmesini sağlamakla ilgili yükümlülüğün (teminat yükümlülüğünün) ihmaline bağlı olarak gerçekleşen ölüm sonucundan kazaya sebebiyet veren kişiyi kasten öldürme suçunun ihmalî davranışla işlenmesinden dolayı, TCK, m. 83 hükümlerine göre sorumlu tutmak gerekecektir.⁶²⁹

c) Olay yerinden hemen ayrıldığı için, **suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme** suçundan (TCK, m. 281),

mahkûmiyet hükmü;

buna karşılık, A'nın yanında bulunan B hakkında **suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme** (TCK, m. 281) ve **yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirmeme** (TCK, m. 98) suçlarından beraat hükmü,

kurmuştur.

Söz konusu kararı temyizen inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise, B'nin **yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme** suçundan (TCK, m. 98) mahkûm edilmesi gerektiği gerekçesiyle, bu kişi hakkında kurulan beraat hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

B'nin ceza hukuku sorumluluğu bağlamında doğru bulduğumuz bu kararda, A'nın kazaya sebebiyet verdikten sonra durmayarak olay yerinden ayrılması ile ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapılmamış olması, önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Dikkat edilmelidir ki, kazaya sebebiyet verdikten sonra durmayarak olay yerinden ayrılması fiilinden dolayı sürücü A hakkında İlk Derece Mahkemesi tarafından **suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme** suçuna (TCK, m. 281) ilişkin hükümlere göre mahkûmiyet hükmü kurulurken, bu kişi bakımından söz konusu olan şahsi cezasızlık sebebi göz önünde bulundurulmamış ve bu durum, Yargıtay incelemesinde gözden kaçırılmıştır.

⁶²⁹ Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 17.5.2018 tarihli ve E. 2017/5844, K. 2018/5668 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, ehliyetsiz ve alkollü olan A, sevk ve idaresindeki araçla, gece vakti, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan B'ye çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet vermesine rağmen, durmayarak, yoluna devam eder. B, kaza sonrası olay mahalline gelen kişilerin yardımıyla hastaneye kaldırılır.

Bu olayla ilgili olarak İlk Derece Mahkemesi A hakkında **taksirle yaralamaya sebebiyet verme** (TCK, m. 88) suçu ile **yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi** (TCK, m. 98) suçundan dolayı ayrı ayrı mahkûmiyet hükmü kurmuştur.

Buna karşılık, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, taksirle yaralamaya sebebiyet veren A "*hakkında yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun kanuni unsurları oluşmadığından, (bu) suçtan beraat*" etmesi gerektiği gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin kurduğu mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

(Aynı yönde diğer bir karar için bkz. Yargıtay 4. CD, 25.12.2015, E. 2014/44736, K. 2015/40855)

Dikkat edilmelidir ki, bu olayda, A, B'ye çarptığının ve B'nin yaralandığının farkındadır. Buna rağmen durmayarak, yoluna devam eder.

Bu tür olaylarda, **ön gelen fiil dolayısıyla teminat yükümlülüğü** söz konusu olduğu için, sorunun TCK, m. 98'de tanımlanan yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu bağlamında ele alınması doğru olmamıştır.

Buna karşılık, karayolu trafik düzenine ilişkin kurallara aykırı herhangi bir davranışı bulunmamasına rağmen, bir başkasının kural ihlali sebebiyle kazaya karışan araç sürücüsü, bu trafik kazasında yaralanan kişilerle ilgili olarak teminat yükümlülüğü altına girmemektedir. Ancak bu sürücü, yaralanan kişilerle ilgili olarak yardım veya bildirim yükümlülüğü altındadır. Bu nedenledir ki, kazaya karışmış olmakla birlikte karayolu trafik düzenine ilişkin kurallara aykırı herhangi bir davranışı bulunmayan araç sürücüsü, bu trafik kazasında yaralanan kişilerle ilgili olarak yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi

Bu tür olaylarda, yaralanan kişinin bilahare ölmüş olması halinde, TCK, m. 83 hükümlerine istinaden ceza sorumluluğu söz konusu olacaktır (Bkz. Yargıtay 12. CD, 4.6.2013, E. 2012/24745, K. 2013/15126).

Karara konu teşkil eden olayda ise B ölmemiştir, yaralanmıştır. Araç sürücüsü A, durumu fark etmesine rağmen, teminat yükümlülüğünün gereğini yerine getirmemiştir. Bu durumda sorunun, görünüşte ihmalî suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanabileceği yönündeki görüş taraftarlarınca, **ihmalî davranışla işlenen kasten öldürme** suçuna **teşebbüs** bağlamında ele alınması gerekir. Görüşümüze göre, ihmalî suçlarda teşebbüse ilişkin hükümler uygulanamayacağı için, sorunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutmak gerekir.

Ölümlü, yaralamalı veya maddi hasarlı trafik kazalarında, kazanın oluşumu bakımından trafik kuralı ihlalinde bulunsun veya bulunmasın, kazaya karışan sürücünün aracının konumunu değiştirmemesi ve olay mahallini terk etmemesi gerekir.

Herhangi bir trafik kuralını ihlal etmiş olmasa bile, kazaya karışan araç sürücüsü,

“Kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise, bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek”,

keza,

“Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak”,

yükümlülüğü altındadır (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, m. 81, f. 1, bent b ve d).

Ayrıca, herhangi bir trafik kuralı ihlal etmiş olsun veya olmasın, kazaya karışan araç sürücüsü *“kaza mahallinde ilk yardım önlemlerini alma(kla) ve en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber verme(kle) ve yetkililerin talebi üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürme”*kle yükümlüdür (2918 s. Kanun, m. 82, f. 1, bent a).

Karara konu teşkil eden olayda, trafik kazasına sebebiyet veren araç sürücüsü, **taksirle yaralamaya sebebiyet verme** suçunun (TCK, m. 89) yanı sıra, 2918 s. Karayolları Trafik Kanunu, m. 81, f. 3’de tanımlanan **kaza mahallini terk etme, kaza mahallindeki durumu değiştirme, kaza ile ilgili olarak bildirimde bulunmama** suçunu işlemiştir. Yani bu gibi durumlarda araç sürücüsü hakkında iki ayrı suçtan dolayı gerçek içtima hükümlerine göre cezaya hükmetmek gerekir.

Bu durumda sorunu, TCK, m. 281’de tanımlanan **suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme** suçu bağlamında da değerlendirmek mümkündür. Ancak, trafik kazasına sebebiyet veren kişi, kendi suçu ile ilgili delilleri yok etmesi, değiştirmesi veya gizlemesi halinde, bu suç bakımından **şahsi cezasızlık** sebebinden yararlanır m. 281, f. 1, ikinci cümle). Belirtmek gerekir ki, bu şahsi cezasızlık sebebi, 2918 s. Karayolları Trafik Kanunu, m. 81, f. 3’de tanımlanan kaza mahallini terk etme, kaza mahallindeki durumu değiştirme, kaza ile ilgili olarak bildirimde bulunmama suçuna teşmil edilemez.

Bu nedenlerle, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin vermiş bulunduğu bu karar, hukuka aykırıdır.

halinde, TCK, m. 98 hükümlerine göre ceza hukuku bakımından sorumlu tutulur.⁶³⁰

⁶³⁰ Yargıtay 12. Ceza Dairesinin **10.3.2020** tarihli ve E. 2020/177, K. 2020/2628 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, A, sevk ve idaresindeki araçla, gece vakti, önünde seyretmekte olan TIR kamyonuna arkadan çarpar. Bu çarpma neticesinde A ile otomobilde bulunan B ve C ölür. TIR aracının şoförü D, durumu fark etmesine rağmen, yoluna devam eder.

Bu olayla ilgili olarak D hakkında **taksirle ölüme sebebiyet verme** suçundan dolayı TCK, m. 85 hükümlerine istinaden soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturmada Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, söz konusu kazanın gerçekleşmesi bağlamında D'nin kusurunun bulunmadığı, "asli kusurun" müteveffa A'ya ait olduğu gerekçesiyle, D hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Bu karara yapılan itiraz, Çorlu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilerek kesinleşmiştir. Adalet Bakanlığı, sulh ceza hakiminin kesin olan kararına karşı aşağıdaki gerekçe ile kanun yararına bozma talebinde bulunmuştur:

*"5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 98. maddesinde düzenlenen yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçu yönünden de soruşturma yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği ve yapılan eksik soruşturma sonucu verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın bu yönden kabulüne karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülme"*miştir.

Yargıtay 12 Ceza Dairesi, bu bozma talebini *"incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmediğinden"* bahisle reddetmiştir.

Hukuki değerlendirmemiz:

Karayolu trafik düzenine ilişkin kurallara aykırı araç kullanarak karıştığı trafik kazasında bir başkasının yaralanmasına sebebiyet veren sürücü, yaralanan kişinin tedavi edilmesini sağlamakla yükümlü kılınmıştır.

Teminat yükümlülüğünün kaynağını oluşturabilmesi için ön gelen fiilin **hukuka aykırı** olması gerekir. Bu itibarla, karara konu teşkil eden olayda olduğu gibi, trafik kazasına karışmakla birlikte, trafik düzenine aykırı bir davranışı bulunmayan, herhangi bir trafik kuralı ihlal etmeyen sürücü, bu trafik kazasında yaralanan kişiler bakımından teminat yükümlülüğü altında bulunmamakla birlikte, kaza ile ilgili olarak yardım veya bildirimde bulunmak yükümlülüğü altındadır. Başka bir ifadeyle, bu sürücü, yaralanan kişilerin ölmesinin önüne geçecek bütün tedbirleri almakla yükümlü kılınmamıştır. Buna karşılık, herhangi bir trafik kuralını ihlal ederek trafik kazasına sebebiyet veren sürücü, bu kazada yaralanan kişilerin ölmesinin önüne geçecek bütün tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Bu nedenle, şayet yaralanan kişiler teminat yükümlülüğünün kasten yerine getirilmemesi sonucunda ölmüş iseler, kazaya sebebiyet veren ve bu nedenle teminat yükümlüsü olan sürücüyü ihmali davranışla işlediği kasten öldürme suçundan (TCK, m. 83) sorumlu tutmak gerekir. Buna karşılık, kazaya karışmayan sair bir kişi veya kazaya karışmakla birlikte herhangi bir trafik kuralı ihlal etmeyen sürücü, muttali olduğu bu trafik kazasında duruma göre yardım veya bildirim yükümlülüğü altına girmektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, TCK, m. 98'de tanımlanan suçu oluşturur. Meydana gelen trafik kazasında kendini idare edemeyecek, kendi başının çaresine bakamayacak şekilde yaralanan kişiler olduğuna muttali olan kişi, duruma göre yardım veya bildirim yükümlülüğü altındadır (Bkz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, m. 82, bent a). Bu yardım veya bildirim yükümlülüğünün kasten yerine getirmemesi, TCK, m. 98 hükümlerine göre ceza hukuku bakımından sorumluluğu gerektirir.

Buna karşılık, **trafik kazasının gerçekleştiği sırada kişilerin ölmüş olduğunu** sair bir kişinin bilahare öğrenmesine rağmen bu kaza ile ilgili olarak bildirimde bulunmaması, TCK, m. 98'de tanımlanan yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunu değil, 2918 s. Karayolları Trafik Kanunu, m. 82 (f. 1, bent a ile bağlantılı olarak), f. 2'de tanımlanan kaza ile ilgili bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunu oluşturur. TCK, m. 98'de tanımlanan suçun oluşabilmesi için, yardım veya bildirim yükümlülüğünün **yaralanan kişilerle ilgili** olarak yerine getirilmemiş olması gerekir.

TCK, m. 98’de tanımlanan suç bakımından yardım veya bildirim yükümlülüğü-nü yerine getirmeyen kişi teminat yükümlüsü olmadığı içindir ki; kazada yaralanan kişinin ölmesi halinde, yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiyi ihmalî davranışla işlenen kasten öldürme suçundan (TCK, m. 83) dolayı sorumlu tutmamaktayız. TCK, m. 98, f. 2 hükmü karşısında, “kaza”da yaralanan kişinin ölmesi halinde, yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiyi sadece bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinden dolayı sorumlu tutmak gerekecektir.⁶³¹

TIR sürücüsünün arkadan aracına çarpan otomobildeki kişilerin **öldüğünü** görmesine rağmen, herhangi bir mercie bildirimde bulunmadan olay mahallini terk etmesi, kazaya karışan kişi olması dolayısıyla, 2918 s. Karayolları Trafik Kanunu, m. 81, f. 3’de tanımlanan **kaza mahallini terk etme, kaza mahallindeki durumu değiştirme, kaza ile ilgili olarak bildirimde bulunmama** suçunu oluşturur.

TIR sürücüsü, arkadan aracına çarpan otomobildeki kişilerin **yaralandığını** görmesine rağmen, yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemiş olsaydı, TCK, m. 98, f. 1’de tanımlanan suç oluşurdu. Kazada yaralanan kişiler bilahare olay yerinde ölmüş olsalardı, TIR sürücüsünün, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinden dolayı TCK, m. 98, f. 2 hükümlerine göre cezalandırılması gerekirdi.

Açıklanan nedenlerle,

- Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığı kararını,
 - bu karara itiraz üzerine Çorlu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği ret kararını,
 - Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebini reddeden Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararını,
- doğru bulmamaktayız.

İlginçtir ki, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, söz konusu olayla ilgili olarak, TIR sürücüsünün durumu ile ilgili olarak hiçbir hukuki değerlendirmede bulunulmadan, ilgili mevzuat hükümlerinden hiç söz etmeden ve soyut bir şekilde “*incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmediğinden*” bahisle Bakanlığın talebini reddetmiştir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesini kararlarında bilimsel kaynaklardan yararlanılmaması, bilimsel görüşlere yer verilmemesi ve en önemlisi, sorunun anlaşılır bir şekilde ifade edilmemesi, dikkat çekici bulunmuştur.

⁶³¹ Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin **7.7.2014** tarihli ve E. 2012/3814, K. 2014/3754 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; A’nın, “*sevk ve idaresindeki kamyonuyla, akşam saat 22.30 sıralarında havanın açık ve asfaltın kuru olduğu Devlet karayolunda, yasal hız sınırları dahilinde seyir halindeyken, akli dengesi yerinde olmayan (B), tam kusurlu bir halde sağ taraftan karşıya geçmek için aniden yola çık(ar), bunun üzerine (A,) sola doğru manevra yapmasına rağmen aracın sağ ön tamponuyla (B’ye) çarpmaktan kurtulama(z); akabinde (A) aracından inerek o sırada ağır yaralı olan (B’nin) durumuna bak(ar), ağır yaralı olduğunu görünce de panik içinde kaza mahallini terk e(der), kaza-nın meydana gelmesinden yaklaşık on dakika sonra jandarma güçleri.. olay yerine ulaş(ır), bu sırada acil tıbbi yardım da isten(ir), ancak (B), olaydan yirmi dakika sonra, ambulansın ulaşmasın-dan kısa bir süre önce, çarpmaya bağlı kafa kemiğinden oluşan çökme kırığı ve beyin kanamasına bağlı solunum ve dolaşım durması sonucu hayatını kaybe*”der.

Dairenin bu olayla ilgili olarak TCK, m. 98 hükümleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler, ancak kamyon sürücüsü A’nın herhangi bir trafik kuralı ihlalinin olmadığı ve dolayısıyla, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan mahkûm edilmediği durumlara münhasır olarak dikkate alınmalıdır.

Daire bu kararda A’nın TCK, m. 98’de tanımlanan **yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi** suçunun temel şekline ilişkin birinci fıkra hükmüne istinaden cezalandırılması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur. Keza Dairenin kabulüne göre, “*meydana gelen olayda ağır ya-*

ralanan ve bu olaydan yaklaşık yirmi dakika sonra olay yerinde ölen maktulün ölümü ile yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi arasında illiyet bağı bulunmamaktadır.”

Daire, İlk Derece Mahkemesinin A hakkında TCK, m. 98’de tanımlanan **yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi** suçunun temel şekline ilişkin birinci fıkra hükmüne istinaden kurduğu mahkûmiyet hükmünün, önemli kısmını, kaynak göstermese bile, bilimsel çalışmalarımızdan iktibas ettiği aşağıdaki gerekçeler ile, onanmasına karar vermiştir.

“Kişinin yaşama hakkını korumak amacıyla ihdas edilen suçlarda neticenin ifade ettiği haksızlık ayıdır. Zira tüm bu suçlarla kişinin yaşamının sona erdirilmesi cezai yaptırıma bağlanmaktadır. Buna karşılık kişinin yaşamını sona erdiren fiiller, işleniş şekillerine, yani hareketin ifade ettiği haksızlığa göre farklı suç tipleri olarak düzenlenmiştir. TCK’da ölüm neticesini cezalandıran suçlar, kasten veya taksirle işlenip işlenmediğine (TCK m. 81, 85); kasten işlenmişse icraî hareketle mi (TCK m. 81), ihmali hareketle mi (TCK m. 83) işlendiğine göre farklı değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Öldürmeyi yasaklayan davranış normunun, kasti, icraî bir hareketle, yani başkasının hayatını sona erdirmeye yönelik aktif bir davranışla gerçekleştirilmesi halinde 81. maddede düzenlenen kasten öldürme suçu işlenmiş olur. Bu suçun oluşması bakımından önemli olan husus, başkasının hayatını ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırının icra edilmiş olmasıdır. Buna karşılık öldürmeyi yasaklayan davranış normu, ihmali bir hareketle de ihlal edilebilir. Bu durumda fail, başkasının hayatını sona erdirmek amacıyla aktif bir davranış gerçekleştirmemektedir. Bu ihtimalde öldürme suçu, başkasının hayatını korumakla yükümlü bulunan kişinin, bu yükümlülüğünü ihlal etmesi suretiyle işlenmektedir. Bu ihtimalde fail, ancak hukuken (kanun, sözleşme, öngelen tehlikeli davranış nedeniyle) başkasının yaşamını korumakla yükümlü bulunan, yani başkasının yaşamına yönelik saldırı veya tehlikeden o kişiyi korumayı hukuken garanti eden kişi olabilir.

Şayet başkasının yaşamını korumak bakımından hukuki yükümlülük altında bulunan kişi, bu yükümlülüğünü ölüm neticesinin gerçekleşeceği bilinciyle yerine getirmezse, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesinden (TCK m. 83) söz edilir. Buna karşılık, böyle bir yükümlülük altında bulunan kişi, yükümlülüğünü bilinçli bir şekilde ihmal etmekle birlikte, bu yükümlülük ihlalini korumakla yükümlü olduğu hayatın sona ereceği bilinciyle yapmamışsa ve fakat bu yükümlülük ihlaline bağlı olarak yine de ölüm neticesi meydana gelmişse taksirle ölüme sebebiyet verme suçu (TCK m. 85) söz konusu olur. Ölüm neticesinin ihmali bir davranışa bağlı olarak meydana geldiği hallerde somut olayın koşulları dikkate alınarak, ölüm neticesi bakımından failin kasten mi, yoksa taksirle mi hareket ettiği dikkatlice belirlenmelidir. Hiç kuşkusuz, ölüm neticesinin kasten meydana geldiği hallerde bunun olası kastla; taksirle meydana geldiği hallerde ise bilinçli taksirle meydana gelip gelmediği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu çerçevede, 83. maddedeki suçun oluşabilmesi için, bu madde uyarınca kanun, sözleşme veya öngelen tehlikeli davranış sebebiyle başkasının yaşamını korumak ve gözetmek yükümlülüğü altında bulunan kişinin, korumak ve gözetmekle yükümlü olduğu hayatın sona erme tehlikesi ortaya çıkmasına rağmen, ölüm neticesinin gerçekleşmesi amacıyla doğrudan kastla veya öngörülen ölüm tehlikesinin meydana gelmesi kabullenilerek olası kastla, sözü geçen hayatı kurtarmaya yönelik icraî bir davranışta bulunmaması gerekir. Örneğin aracıyla giderken çarptığı kişinin yaralanarak yere düşmesine neden olan sürücü, öngelen tehlikeli davranış sebebiyle yaraladığı kişinin hayatını kurtarmakla yükümlüdür. Sürücü yaraladığı kişiye yardım etmek veya yardım edecek birilerini çağırarak, yani yaralananın ölmemesi için gerekli çabayı göstermek yükümlülüğü altındadır. Buna rağmen sürücü aracını durdurmaz ve çarptığı kişinin ölmesi amacıyla ona yardım etmezse 83. maddedeki suçu kasten işlemiş olur.

Olayımızda olduğu gibi; öngelen davranış gerçekleştirmiş olmasına rağmen bu davranış gerçekleştirmekte kusursuz olan kişinin ise 83. madde uyarınca değil, tıpkı başka birisinin yaraladığı kişiyi görmesine rağmen yardımdan imtina eden kişide olduğu gibi 98. madde uyarınca sorumlu tutulması gerekir.

Her ne kadar, 83/2-b maddesinde öngelen davranış yapan kişinin sorumluluğu belirlenirken “kusurun bulunup bulunmaması” hususundan bahsedilmemiş ise de, öngelen davranışta hiçbir kusuru bulunmayan kişinin de bu madde uyarınca sorumlu tutulması, TC’K’nın “hayata

Bu yönü itibarıyladır ki, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun işlenmesi sonucunda ölüm neticesi meydana gelmiş olsa bile, bu suç **gerçek ihmalî suç** olma özelliği taşımaya devam eder. Bu nedenledir ki, gerçek ihmalî suçlarla görünüşte ihmalî suçlar arasındaki ayırım ölçütü, netice olamaz.⁶³² Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu ayırımın dayandığı temel ölçüt, teminat yükümlülüğünün mevcut olup olmamasıdır.

karşı suçlar” bölümünde düzenlenen 83. madde ile korunmuş bulunan hukuki değer ile bağdaşmaz. Zira, 83. maddedeki suçla “kişilerin yaşama hakkı” korunmaktadır. Bu durumda ise failin, mağdurun “yaşama hakkına” yönelik kusurlu bir eylemi bulunmamaktadır. Failin eylemi, yaşama hakkı tehlikeye girmiş bir kişiye yardımdan imtina etmekten ibarettir.”

Ancak, söz konusu kararda varılan A’nın TCK, m. 98’in *birinci fıkrası* hükmüne istinaden cezalandırılması gerektiğine dair sonuç ve bu sonuca ulaşmanın gerekçesi olarak nedensellik bağı ile ilgili olarak yapılan açıklamalar sorunludur:

TCK, m. 98’in ikinci fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için, “*yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi şeklinde gerçekleşen hareketle (yardıma muhtaç kişinin ölümü) arasında bir illiyet bağının bulunması*” gerekir. Oysa, söz konusu “*olayda ağır yaralanan ve bu olaydan yaklaşık yirmi dakika sonra olay yerinde ölen maktulün ölümü ile yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi arasında illiyet bağı bulunmamaktadır.*”

Daire bu kararında, ihmalî suçlarda *farazi anlamda nedensellik bağlantısının* varlığı düşüncesine dayanmıştır. Oysa ihmalî suçlarda meydana gelen neticeden sorumluluk için, nedensellik bağına gerek bulunmamaktadır. Burada önemli olan, gerçekleşen neticenin kişiye objektif olarak isnat edilebilmesidir. Bunun için de, somut olayda kişinin yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirebilme imkânına sahip olması gerekmektedir. Bu imkânın varlığına rağmen yardım veya bildirimde bulunmaktan sarfinazar edildiğinde, yardıma muhtaç olan kişi ölmüş ise, TCK, m. 98, f. 2 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekir. Bu gibi durumlarda, yardım veya bildirim yükümlülüğünün gereği yerine getirilmiş olsaydı dahi yardıma muhtaç olan kişi ölecekti şeklinde bir gerekçe ile, ikinci fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmetmekten sarfinazar edilemez. Oysa Daire, yardıma muhtaç kişinin ağır surette yaralanmış olmasını dikkate alarak, esasında bu mülahaza ile birinci fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilmesi gerektiği içtihadında bulunmuştur.

⁶³² Yargıtay 4. Ceza Dairesinin çeşitli kararlarında, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu ile ilgili olarak doktriner kaynaklardan iktibas edilerek şu genel açıklamalara yer verilmiştir:

“Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu ile korunmak istenen hukuki değer, kişilerin yaşam hakkı ve vücut bütünlüğünün korunmasıdır. Ayrıca bu suçla, toplumda birlikte yaşayan bireylerin, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye “ahlaki ve sosyal bir ödev” olan yardım ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri amaçlanmış ve toplumsal dayanışmanın bu suretle yaşatılması hedeflenmiştir.

Yardım veya bildirim yükümlülüğü medeni toplumlarda toplumsal ve sosyal hayatın gerekliliklerinden kaynaklanmaktadır. Bireylerin, zayıfları koruma ve yardım etme görevinin bulunduğu kabul edilir. Ayrıca bu yükümlülüklerin ahlaki bir yönü de vardır. Bu düzenleme ile bireylerin yardıma muhtaç olduğu durumlarda, diğer kişiler bakımından yardımda bulunma ya da en azından ilgili makamlara durumu haber verme mecburiyeti getirilip, yardıma hukuki bir nitelik kazandırılarak, aykırı davranışlar cezai yaptırıma bağlanmıştır.

*Suçun maddi unsuru yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan bir kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde “Yardım etmemek” yada “durumu derhal ilgili makamlara bildirmemek” şeklindeki ihmalî davranışlardır. Kanun koyucu iki tür ihmalî davranış öngörmüştür. Bunlardan birinin varlığını suçun oluşumu için yeterli görmüştür. Burada **seçimlik hareketli bir suç** söz konusu olup, her iki harekette ihmalî niteliktedir.*

Failin yardım etmeme nedeniyle sorumlu tutulabilmesi, failin kendisini veya bir başkasını tehlikeye sokmadan, olanakları, gücü ve yeteneğiyle orantılı biçimde, hal ve koşullara göre **yardım yapmasının mümkün olduğunun** tespitine bağlıdır. Yardım yapmanın mümkün olduğu sonucuna varıldığında, bu yardımın biçimi ve kapsamı, somut olayın özelliklerine göre, bu bağlamda failin kişisel ve fiziksel özellikleri ile deneyimi, bilgisi, sahip olduğu araçlar, tehlikenin boyutu, ayrıca ani gelişen olaylarda failin şoka girip girmediği de gözetildikten sonra mahkemece takdir edilecektir. Failden beklenen yardım, mağdur için halen var olan zarar ve tehlikenin genişlememesine yönelik ve buna uygun olan koruyucu faaliyetler olabilir. Ancak yardımın yeterli olamayacağı belli ise, failin sorumluluktan kurtulması için durumu derhal ilgili makamlara bildirmesi gerekir. Bildirim yükümlülüğü, iletişim vasıtası cihazlarla, el kol hareketleri ile yazılı veya sözlü olarak yahut herhangi bir biçimde yerine getirilebilir. Belirtilen durumlara maruz kalmış bir kimseyle karşılaşan kişinin hal ve koşullara göre öncelikle mağdura yardım etmesi, mümkün olmaması veya yardımın yetersiz kalacağının anlaşılması halinde ise durumu derhal ilgili makamlara bildirmesi gerekir. Hemen belirtmek gerekir ki, başkalarının yardım veya bildirimde bulunması, failin yardım veya bildirimde bulunmasını gereksiz kılmış ise, bu durumda bu suçun oluştuğundan söz edilemez.

Bildirimin derhal yapılması, hal ve koşullara göre en uygun bildirme yönteminin tercih edilerek yükümlülüğün gecikmeye meydan vermeksizin durumun ilgili makamların bilgisine iletilmesidir. İlgili makamlardan maksat ise soruşturma yapmakla görevli adliye ve kolluk makamları ile durumu adli makamlara bildirmekle yükümlü diğer resmi kurumlardır.

Suçun mağduru, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan bir kimsedir. Mağdur yaşayan gerçek bir kişi olmalıdır. Suç tipinde mağdurun yaşı, yaralanması veya hastalığı tek başına mağduriyet için şart olarak ön görülmemiştir. Suçun oluşumu için ayrıca mağdurların sayılan sebeplere bağlı olarak kendilerini idare edememesi gereklidir. Mağdurun ne sebeple yardıma muhtaç olduğunun ise önemi yoktur.

Kendini idare edemeyecek durumda olma hali ile kastedilen, mağdurun, bir başkasının yardımını olmadığı takdirde, **hayatına, sağlığına veya vücut bütünlüğüne yönelik ağır bir tehlikenin mevcudiyeti** olması şeklinde anlaşılmalıdır.

Suçun faili olaya sebebiyet veren kişi dışındaki herkes olabilir. Failin, mağdurun yardıma muhtaç hale gelmesine kasta veya taksire dayalı hareketiyle neden olması halinde, failden yardım veya bildirimde bulunması beklenemez; bu nedenle fail sadece işlediği suçtan sorumlu olur. Ancak olaya sebebiyet veren kişi, mağdura yardım konusunda kendiliğinden inisiyatif almış, bu nedenle başkalarının yardım etmesine ve resmi mercilere bildirmesine engel olmuş ve buna rağmen yardımı gerçekleştirilmemiş ise, kendiliğinden üstlendiği yardım yükümlülüğünü yerine getirmediği için, fail olarak bu suçtan sorumlu tutulmalıdır.

Fail mağduru koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kişi ise, bu durumda **terk suçundan** söz edilebilir. Failin neticeyi önleme konusunda hukuki bir yükümlülüğü mevcut ise yükümlülüklere aykırı davranışların, diğer şartların da mevcut olması halinde 83. maddede düzenlenen kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ya da 88. maddede düzenlenen kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun konusu, madde metninde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde mağdurun yaralanması veya zarar görmesidir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle mağdurun ölmesi halinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Maddenin birinci fıkrasında “**tehlike suçu**” olarak düzenlenen bu suçun manevi unsuru kasttır. Fail, mağdurun kendini idare edemeyecek durumda olduğunu, yardım veya bildirimde bulunduğu takdirde tehlikenin ortadan kaldırılabileceğini bilecek ve buna rağmen bu yükümlülükleri yerine getirmemeyi isteyecektir.

Maddesinin ikinci fıkrasında, **netice sebebiyle ağırlaşmış suç** haline ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda faile ikinci fıkradaki ağırlaştırılmış ceza uygulanacaktır. Ancak fai-

VIII. TCK, m. 257’de tanımlanan görevi kötüye kullanma suçu, icraî davranışla işlenebileceği gibi (f. 1), ihmali davranışla da işlenebilir (f. 2). Ancak belirtmek gerekir ki, görevin gereği olan belirli bir icraî davranışta bulunmamak, görevin gereğinin salt yerine getirilmemesi, bu suçu oluşturmamaktadır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, üstlendiği kamu görevinin gereğini yerine getirmeyen kişinin bu ihmali sonucunda, **objektif cezalandırılabilme şartı** olarak, kamu açısından ekonomik zararın doğması, birisinin haksız menfaat elde etmesi veya bir mağduriyete maruz kalması gerekir.⁶³³ Başka bir ifadeyle, söz konusu suçun oluşabilmesi için, kamu açısından oluşan ekonomik zararın, kişinin elde ettiği haksız menfaatin veya kişinin maruz kaldığı mağduriyetin, görevinin gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisine isnat edilebilir olması gerekir (**objektif isnadiyet**).^{634 635}

lin bu ağır sonuçtan sorumlu tutulabilmesi için TCK’nın 23. maddesi uyarınca netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.

Suç tehlike suçu olmasının yanı sıra ihmali suç niteliğindedir. İhmal kesintisiz bir nitelik taşıdığından, diğer yandan sonuca ulaşmamış bir ihmali hareketi değerlendirebilmek ve hangi sonuca yöneldiğini anlayabilmek imkânı bulunmadığından, bu suça teşebbüs mümkün değildir.

Yardım veya bildirim yükümlülüğüne aykırı davranan her kişinin ihmali davranışı ayrı bir suçu oluşturacağı için prensip itibarıyla bu suçta şeriklik mümkün değildir. İstisnai olarak ortaklık ancak, yardım veya bildirim yükümlülüğü bulunmayan, dolayısıyla, fail olmayan bir kişinin bu konuda yükümlülüğü bulunan faili azmettirmesi suretiyle mümkün olabilecektir.

Fail maddede öngörülen seçimlik ihmali davranışların ikisini birden gerçekleştirdiğinde, bir başka deyişle hem yardım hem de bildirim yükümlülüklerini ihlal ederse, tek bir suçtan sorumlu olur. Ayrıca yardıma muhtaç birden fazla kişi mevcutsa, aynı neviden fikri içtima kuralı uyarınca tek bir cezaya hükmedilmekle birlikte, bu ceza TCK’nın 43/2. maddesi gereğince artırılır. Öngelen tehlikeli durum nedeniyle mağdurun kendini idare edemeyecek duruma gelmesine fail neden olmuşsa ve bu nedenle ölüm gerçekleşmişse, anılan Kanunun 83. maddesinde tanımlanan ihmal suretiyle kasten öldürme suçundan sorumlu tutulması gerekir.” Yargıtay 4. CD, **25.12.2015**, E. 2014/34362, K. 2015/40853; Yargıtay 4. CD, **25.12.2015**, E. 2014/44736, K. 2015/40855; Yargıtay 4. CD, **18.1.2015**, E. 2015/27008, K. 2016/615.

⁶³³ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *İrtikâp, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları*, 2. bası, Ankara, Haziran 2013, sh 149 vd.

⁶³⁴ Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 28.3.2014 tarihli ve E. 2010/30773, K. 2014/9775 sayılı kararına konu teşkil eden olayda, Belediye aleyhine açılan tam yargı davasında, dava dilekçelerine ve İdari Mahkemesi tarafından gönderilen müzakkerele Belediye adına cevap verilmez. İdare Mahkemesi tarafından ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine açılan kamu davasında İlk Derece Mahkemesinin Belediye Mali Hizmetler Servisinde Müdür olan A ile Belediye Başkanı B hakkında verdiği beraat kararı aşağıdaki gerekçe ile bozulmuştur:

İdare mahkemesinin “görülen davalar nedeniyle Belediyece yanıtlanması için yazdığı müzakkerele konu hususların sanık A’nın görevli olduğu Mali Hizmetler Servisinde yanıtlanmasının gerektiği ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/k maddesinde öngörülen Belediye Başkanının Belediye-yi denetlemek görevi kapsamında, Belediyeden istenilen bilgi ve belgelere ilişkin mahkeme yazılarına cevap verme konusundaki sorumluluğun nihai olarak Belediye Başkanına ait olması nedeniyle Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen ara kararların, yapılan ihtarlara rağmen Belediye Başkanlığı tarafından yerine getirilmemesi üzerine görülmekte olan davaların uzadığı ve böylece davacıların adil yargılanma haklarının ihlal edilmesi suretiyle mağduriyetlerine sebebiyet verildiğinin anlaşılması karşısında, sanıkların eylemlerinin TCK’nın 257/2. maddesine uyduğu gözetilmeksizin, yasal olmayan ve yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi,” hukuka aykırıdır.

Ancak belirtmek gerekir ki, Yargıtay'ın pek çok kararında, görevi kötüye kullanma suçunun ihmali davranışla işlenmesi, açıkça ifade edilmese bile, “taksirli” suç olduğu izlenimi oluşturacak şekilde uygulama geliştirilmiştir.⁶³⁶

Keza, bazı olaylarda, kamu görevlisinin fiili icraî davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu halde, TCK, m. 257, f. 2 hükmüne istinaden cezaya hükmedilmesi gerektiği yönünde içtihatla bulunulmuştur.⁶³⁷

IX. TCK, m. 251’de, gözetim ve denetim görevinin ihmali sonucunda zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesi halinde ceza sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Söz konusu maddede iki farklı duruma ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Birinci durumda, kamu görevlisi, gözetlemek ve denetlemekle görevli olduğu faaliyet alanında zimmet veya irtikâp suçunun işlenmekte olduğu bilgisine muttali olmasına rağmen, suçun işlenmesini önleme yönünde bir girişimde bulunmaz. Madde gerekçesinde de ifade edildiği gibi, “*bu durumda, kamu görevlisi, zimmet veya irtikâp suçunun işlendiğinden haberdardır ve buna rağmen dene-*

⁶³⁵ ... Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapan S’nin ... Çocuk Mahkemesinde yargılanan suça sürüklenen çocuklara CMK, m. 150, f. 2 hükümleri gereğince “zorunlu müdafî olarak atanmasına rağmen, mahkemenin ... tarihlerinde yapılan celselerine mazeretsiz katılmayarak davanın gereksiz uzaması sonucu kamu zararına, adaletin gecikmesi nedeniyle de kişi mağduriyetine neden olduğunun” anlaşılması karşısında, fiili TCK, m. 257, f. 2’de tanımlanan “**ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu oluştur**”ur: Yargıtay 5. CD, **5.5.2014**, E. 2013/1029, K. 2014/5008.

Ayrıca bkz. Yargıtay 4. CD, **5.1.2015**, E. 2014/4652, K. 2015/140; Yargıtay 4. CD, **4.10.2012**, E. 2011/22078, K. 2012/19742; Yargıtay 4. CD, **1.6.2015**, E. 2015/11947, K. 2015/30234; Yargıtay 5. CD, **20.3.2014**, E. 2012/16008, K. 2014/3224; Yargıtay 5. CD, **30.3.2015**, E. 2013/7361, K. 2015/9033.

⁶³⁶ Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 30.5.2013 tarihli ve E. 2011/5345, K. 2013/16792 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, şeker ve yüksek tansiyon hastası olan G gebelik takibi için Devlet Hastanesine başvurur. Hastanede yapılan tetkik ve muayenede G’nin açlık kan şekerinin ve tansiyonunun yüksek olduğu tespit edilir ve G düşük yapar.

Bu olayla ilgili olarak İlk Derece Mahkemesi S’nin beraatine hükmetmiştir. Ancak, Daire, muayeneyi yapan kadın doğum uzmanı olan S’nin, G’nin kan şekerini ve tansiyonunu düzenlememek ve yüksek riskli gebelik grubunda olması dolayısıyla bir üst sağlık kuruluşuna sevkini önermeyerek kusurlu bulunduğunu, hastanedeki kamu görevi sırasındaki bu ihmali davranışı ile gerekli sağlık hizmetini alamayan hastanın mağduriyetine neden olarak, **ihmalî davranışla görevi kötüye kullanma suçunu** (TCK, m. 257, f. 2) işlediğini kabul ederek, İlk Derece Mahkemesinin beraat hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Ayrıca bkz. Yargıtay 4. CD, **19.1.2015**, E. 2014/35932, K. 2015/1400.

Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi olan A, B ve C’nin TCK, m. 251, f. 2 hükmüne göre “*dene-tim yükümlülüklerinin bulunmadığı, kooperatifin tüm parasal işlemlerini yürüten D’nin hazırladığı evrakları gerekli özeni göstermeden imzala*”mak suretiyle TCK, m. 257, f. 2’de tanımlanan “*ihmalî davranışla görevi kötüye kullanma suçunu*”u işledikleri” kabul edilmiştir: Yargıtay 5. CD, **27.5.2014**, E. 2013/2591, K. 2014/5804.

⁶³⁷ Yargıtay 4. CD, **22.1.2013**, E. 2011/5488, K. 2013/1081.

*tim görevini kasten ihmal etmektedir.*⁶³⁸ Bu durumda, gözetim ve denetimle yükümlü kamu görevlisi, bir başkasının işlediği zimmet veya irtikâp suçuna **ihmalî davranışla iştirak** etmiştir. Ancak, bu suçtan dolayı şerik sıfatıyla değil, **müşterek fail** sıfatıyla sorumlu tutulacaktır.

İkinci durumda ise, gözetim ve denetimle yükümlü kamu görevlisinin bu görevini ihmal etmesinden yararlanılarak zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesi söz konusudur. Bu durumda da kamu görevlisi, gözetim ve denetim görevini **kasten ihmal** etmektedir.^{639, 640} Ancak, gözetmek ve denetlemekle görevli olduğu faaliyet alanında zimmet veya irtikâp suçunun işlenmekte olduğu bilgisine muttali değildir. Bu nedenle, işlenen zimmet veya irtikâp suçuna iştirak ettiği kabul edilemez. Bu nedenledir ki, kamu görevlisinin gözetim ve denetim görevini kasten ihmal etmesi, TCK, m. 251, f. 2’de **ayrı bir suç** olarak tanımlanmıştır.^{641, 642}

⁶³⁸ Bkz. TCK, m. 251 gerekçesi (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 646 vd.).

⁶³⁹ Bkz. TCK, m. 251 gerekçesi (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 646 vd.).

⁶⁴⁰ “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörünün yaptığı denetim sonucunda Belediyede tahsildar olan X’in tahsil ettiği gelirlerin bir kısmını kullanıp belediye hesaplarına geç yatırmak, bir kısmını ise hiç yatırmamak suretiyle zimmet suçunu işlediği anlaşılmış ise de, işlemleri denetlemekle görevli sanıklar Belediye Başkanı Y ile ... Hizmetler Müdür Vekili Z’nin zimmet eylemine kasten göz yumduklarını gösteren mahkumiyetlerine yeterli somut, tarafsız ve kesin kanıtın bulunmadığı, sabit olan tahsilat ve harcama işlemlerini denetlememe fiillerinin TCK’nın 251/2. maddesine uyan denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama suçunu oluşturduğu ve hükmün gerekçesinde de eylem bu şekilde nitelendirildiği halde, zimmet suçunun işlendiğini bildiklerine ve kasten göz yumduklarına ilişkin deliller karar yerinde açıklanmadan, çelişkili ve yetersiz gerekçelerle TCK’nın 251/1. maddesi yollaması ile zimmet suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi,” hukuka aykırıdır: Yargıtay 5. CD, 25.4.2016, E. 2014/3118, K. 2016/4201.

“İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol komutanı olarak görev yapan sanık X’in, soruşturma konusu olan suç eşyalarının bulunduğu deponun denetimini yapmayarak diğer sanık Y’nin zimmet suçunu işlemesine sebebiyet verdiği kabul edilen olayda; eylem.. denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama suçunu oluştur”ur: Yargıtay 5. CD, 7.11.2016, E. 2014/7224, K. 2016/8820.

⁶⁴¹ Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 27.5.2014 tarihli ve E. 2013/2591, K. 2014/5804 sayılı Kararına konu olan, kooperatifin finans işlerini takip eden çalışanının, düzenlediği ödeme belgelerini kooperatif yönetim kurulu üyelerine gerekli incelemeleri yapmadan imzalatarak, kooperatif bütçesinden fazla ödeme yapılmasını sağladığı ve bu suretle zimmetine para geçirdiği olayda, kooperatif yönetim kurulu üyelerinin bu zimmet suçuna iştiraktan dolayı sorumlu tutulamayacakları izahtan varestedir. Ancak, bu durumda her ne kadar zimmet suçunun işlenmesine yönelik kastları mevcut değilse de, kooperatif yönetim kurulu üyeleri, kooperatif bütçesinden ödeme yapılmasını gerektiren belgeleri incelemeyi ve içeriklerinin doğruluğunu kontrol etmeyi kasten ihmal etmişlerdir. Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, önlerine konulan ödeme belgelerini incelemeyi, doğruluğunu kontrol etmeden imzalayarak, kooperatifin finans işlerini takip eden çalışanının zimmet suçunu işlemesini sağlamışlardır. Bu durumda, kooperatif yönetim kurulu üyeleri bakımından TCK, m. 251, f. 2’de tanımlanan suçun oluştuğunu kabul etmek gerekirdi. Ancak Daire, kooperatif yönetim kurulu üyelerinin kooperatifin faaliyetlerini denetleme yükümlülüğünün bulunmadığı gerekçesiyle bu olayda TCK, m. 251, f. 2’de tanımlanan suçun değil, ihmalî davranışla görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğu yönünde içtihatla bulunmuştur. Oysa, Dairenin ka-

Ancak, belirtmek gerekir ki, TCK, m. 251, f. 2’de tanımlanan suçun oluşabilmesi için, kamu görevlisinin gözetim ve denetim görevini kasten ihmal etmesi yeterli değildir; bu gözetim ve denetimin yapılmamasından yararlanılarak zimmet veya irtikap suçunun işlenmesi gerekir.⁶⁴³ Başka bir ifadeyle, söz konusu suçun oluşabilmesi için, kamu görevlisinin gözetim ve denetim görevini salt ihmal etmesi, söz konusu suçu oluşturmaz. Bu nedenle, **gözetim ve denetim görevinin ihmal edilmesine bağlı olarak zimmet veya irtikap suçunun işlenmesi**, bu suç bakımından bir **objektif cezalandırılabilme şartı** mahiyeti taşımaktadır. Bu özellikleri itibarıyla TCK, m. 251, f. 2’de tanımlanan söz konusu suç, ihmalî davranışla işlenen görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şeklini oluşturmaktadır.⁶⁴⁴

bulünün aksine, kooperatif yönetim kurulu üyeleri, bu görevlerinin gereği olarak, kooperatifin faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle yükümlüdürler.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, ... Esnaf ve Sanatkarlar Odasında gerçekleşen zimmet fiilinden dolayı Oda Yönetim Kurulu üyelerinin ihmalî davranışla görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin TCK, m. 257, f. 2 hükmüne, Oda Denetim Kurulu üyelerinin ise, TCK, m. 251, f. 2 hükmüne istinaden cezalandırılmaları gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur: Yargıtay 5. CD, **27.3.2015**, E. 2013/5381, K. 2015/8953. Ayrıca bkz. Yargıtay 5. CD, **18.3.2015**, E. 2013/7493, K. 2015/8470; Yargıtay 5. CD, **18.2.2020**, E. 2016/3080, K. 2020/6243.

Dairenin, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ceza hukuku sorumluluğu bakımından yaptığı bu ayrımını hukuki dayanağı bulunmamaktadır. TCK, m. 251, f. 2’de tanımlanan suç bakımından önemli olan, kamu görevlisinin gözetmek ve denetlemekle görevli olduğu faaliyetin icrası sürecinde zimmet veya irtikap suçunun işlenmesi ve bu suçun işlenmesinde gözetim ve denetim görevinin yapılmamasından yararlanılmasıdır. Denetim kurulu üyeleri ve denetçiler, bir iş veya işlem yapıldıktan sonra denetim faaliyetini icra ederler. Bir iş veya işlemin icrası tamamlandıktan sonra bunların hukuka uygun olarak icra edilmiş olup olmadığını denetleyen denetim elemanlarının, bu görevlerinin icrasıyla zimmet veya irtikap suçunun işlenmesini sağlamaları söz konusu olamaz. Bu durumda ancak, icrası tamamlanmış olan zimmet veya irtikap suçunun gizlenmesi söz konusu olabilir. Oysa, TCK, m. 251, f. 2’de tanımlanan suç bakımından önemli olan, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmemesinden yararlanılarak zimmet veya irtikap suçunun işlenmesidir. Ancak, gözetim ve denetimle görevli kamu görevlisi, bu suçların işlenişine iştirak etmemektedir.

⁶⁴² Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 18.1.2018 tarihli ve E. 2017/6340, K. 2018/202 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan A’nın, muhasebe servisinde çalışan B tarafından hazırlanan sahte mahkeme ilamlarına dayanılarak oluşturulan beş ayrı tahakkuk evrakını gerçekleştirme görevlisi olarak **‘kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür’** şerhleri ile imzalayarak görevini ihmal ettiği iddiasıyla TCK’nın 251/2. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de; Daire tarafından, münnet fiilin TCK, m. 257, f. 2’de tanımlanan *ihmalî davranışla görevi kötüye kullanma* suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunulmuştur.

⁶⁴³ Bir kamu kurumunda *“il müdürü ve muhasebeden sorumlu şube müdürü olarak görev yapan A ve B’nin, emirleri altında görev yapan C ve D’nin yürüttüğü işlemleri hiç denetlememek ve imzalarına sunulan muhasebe evrakı üzerinde gerekli incelemeleri yapmamak suretiyle uzunca bir zaman dilimine yayılan bir kısmı nitelikli, bir kısmı basit zimmet vasfındaki fiillerin işlenmesine imkan sağladıkları sabit olduğu ve eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK’nın 251/2. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları gerektiği halde, (haklarında) beraat kararları verilmesi”* hukuka aykırıdır: Yargıtay 5. CD, **25.3.2014**, E. 2013/7995, K. 2014/3318.

⁶⁴⁴ Bkz. GÖKCAN, Hasan Tahsin: *Türk Ceza Kanunundaki Bazı Genel ve Özel Nitelikli Kamu Görevi Yükümlülük Suçları, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, İrtikap, Rüşvet ve Denetim Görevini İhmalî Suçları*, Ankara 2022, sh. 769 vd.

X. TCK, m. 278’de tanımlanan “Suçu bildirmeme” suçu ile korunan hukuki değerin, barış esasına dayalı Hukuk Toplumu ve kişilerin bu toplumda yaşama hakkı olduğu, madde gerekçesinde açık bir şekilde ortaya konulmuştur:

*“Barış esasına dayalı Hukuk Toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına sahiptir. Suç teşkil eden bir fiilin işlendiğini öğrenen bireyin, bununla ilgili olarak yetkili makamlar nezdinde **bildirimde bulunma hakkı** vardır. Bu bakımdan, belli bir suç vakasıyla ilgili olarak bildirimde bulunmak, **hukuka uygunluk nedeni olarak bir hakkın kullanılmasından ibarettir.***

*Suçluların cezalandırılmasını devletten istemek, kişi açısından bir hak olduğu gibi; herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenen kişinin durumu suçu takibe yetkili makamlara bildirmesi, aynı zamanda bir **yükümlülüktür**. Bu itibarla, herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenmesine rağmen durumun suçu takibe yetkili makamlara **bildirilmemesi**, genel olarak **haksız** bir davranıştır. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince sadece belli suçların bildirilmemesi veya sadece belli kişilerin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, suç olarak tanımlanmıştır.”⁶⁴⁵*

Bu itibarla, söz konusu maddede, belli suçlar bakımından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, suç olarak tanımlanmıştır.

Bu maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturan yani kişilerin bildirmekle yükümlü oldukları suçun, henüz **icrası devam etmekte** olan yani **işlenmekte olan bir suç** olması gerekir.

TCK, m. 109’da tanımlanan **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma** suçu bu bağlamda önemli bir örnek oluşturmaktadır. Keza, söz konusu madde gerekçesinde de vurgulandığı üzere, bilahare karşılıksız yararlanma suçuna dönüştürülen **elektrik hırsızlığı** gibi **kesintisiz (mütemadi) suçlar**, icrası devam ettiği sürece, bu duruma muttali olan kişiler bakımından bildirim yükümlülüğü kapsamına girmektedirler.

Yapı ruhsatıyesı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapılması (TCK, m. 184, f. 1) da, bu suçun konusunu oluşturabilir.

Bu bakımdan, bildirim yükümlülüğünün kapsamına giren suçun mutlaka kasten işlenen bir suç olması gerekmemektedir. **Çevrenin kasten kirletilmesi** (TCK, m. 181) gibi **çevrenin taksirle kirletilmesi** suçu (TCK, m. 182) da bu suçun konusunu oluşturabilir. Başka bir ifadeyle, **taksirli suç** da bildirim yükümlülüğünün konusunu oluşturabilir.

⁶⁴⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 668.

Keza, **icrası tamamlanmış** olmakla birlikte, **sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan suçlar** da, bildirim yükümlülüğü kapsamına girmekte ve dolayısıyla, 278. maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturmaktadır.

Madde gerekçesinde yer alan örneğe göre, “*icrası tamamlanmış olan bir hırsızlık sonucunda elde edilmiş olan malların bir depoda saklandığının bilinmesine rağmen, durumdan yetkili makamların haberdar edilmemesi, bu suçu oluşturmaktadır.*”⁶⁴⁶ Keza, örneğin hırsızlık suçu işlenmek suretiyle elde edilen eşyayı bir başkasının kullandığına, suçtan elde edildiği bilinerek kabul edilen eşyayı kullanmaya devam edildiğine muttali olunması halinde de, bildirim yükümlülüğü doğmaktadır. Bu bildirim yükümlülüğünün kasten yerine getirilmemesi de söz konusu suçu oluşturmaktadır.

Bildirim yükümlülüğünden söz edebilmemiz için, 278. maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturan suçun işlenmekte olduğuna veya işlendiğine soruşturma makamlarının henüz muttali olmamış olması, yani bu suç dolayısıyla soruşturma işlemlerinin henüz başlatılmamış olması gerekmektedir. Suçun işlenmekte olduğuna veya işlendiğine soruşturma makamları muttali olmuş ise, kişiler bakımından artık bildirim yükümlülüğünden söz edilemez.

Ancak, kesintisiz (mütemadi) suçun işlenmesine son verilmiş ise, örneğin hürriyeti tahdit edilen kişi serbest bırakılmış ise, soruşturma makamları henüz durumdan haberdar olmamış olsalar bile, kişiler bakımından artık bildirim yükümlülüğünden söz edilemez.

Bildirim yükümlülüğü, suçun işlenmekte olduğuna veya işlendiğine muttali olduğu andan itibaren doğar ve soruşturma makamları durumdan haberdar oluncaya kadar devam eder. Bu itibarla, işlenmekte olduğuna veya işlendiğine muttali olduğu suç dolayısıyla soruşturma başlayıncaya kadar bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, 278. maddede tanımlanan suçu işlemeye devam etmektedir. Başka bir ifadeyle, 278. maddede tanımlanan suç, **gerçek ihmali suç** ve **kesintisiz (mütemadi) suç** niteliği taşımaktadır. Bildirim yükümlülüğünün salt yerine getirilmemesi, bu suçu oluşturmaktadır.⁶⁴⁷

Suçu bildirmeme suçu, ancak **doğrudan kastla** işlenebilir. Söz konusu maddenin birinci ve ikinci fıkraları metinlerinde açıkça vurgulanmış olmamakla birlikte, bu fıkralara ilişkin gerekçelerde yer verilen “**bilinmesine rağmen**” veya “**haberdar olunmasına rağmen**” ibareleri, söz konusu suçun ancak doğrudan kastla işlenebileceğini ifade etmektedir.⁶⁴⁸

⁶⁴⁶ Madde gerekçesinde yer alan bu açıklama ile ilgili olarak **doğru olmayan** yaklaşımla yapılan değerlendirmeler için bkz. ERDEM, Mustafa Ruhan: *Suçu Bildirmeme Suçu (TCK, m. 278)*, in: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, yıl 21, sayı 80, Ocak-Şubat 2009, sh. 105 vd., 113.

⁶⁴⁷ Bu nedenle, 278. maddede tanımlanan suçun “somut tehlike suçu” olduğu yönündeki görüş (ERDEM, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 80, sh. 108) doğru değildir.

⁶⁴⁸ Keza, TCK’nın 279. maddesinde tanımlanan **kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu** da ancak **doğrudan kastla** işlenebilir. Çünkü söz konusu suçun oluşabilmesi için bir suçun işlendiğinin kamu

278. maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturan suçun işlenmekte olduğuna veya işlendiğine muttali olan **herkes bakımından bildirim yükümlülüğü** mevcuttur ve dolayısıyla, herkes 278. maddede tanımlanan suçun faili olabilir.⁶⁴⁹

278. maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturan suçu işleyen veya bu suçun işlenmesine iştirak eden kişi bu suçun işlendiğini gören, öğrenen diğer bir şahsı kendisini ihbar etmeme, bu suçla ilgili olarak bildirimde bulunmama konusunda yönlendirebilir, azmettirebilir. Bu yönlendirmenin, azmettirmenin bir haksızlık oluşturduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. Ancak, 278. maddede tanımlanan suçun konusunu oluşturan suçun faili veya sair suç ortağı ile ilgili olarak suçu bildirmeme suçu bakımından bir **şahsi cezasızlık sebebinin** olduğunu kabul etmek gerekir. Zira, kimse kendini suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamaz (Any, m. 38, f. 5).

Keza, tanıklıktan çekinebilecek olan kişilerle ilgili olarak da 278. maddede tanımlanan suç bakımından **şahsi cezasızlık sebebi** söz konusudur (TCK, m. 278, f. 4).

Ancak, işlenmekte olan suçun işlenmesini önleme bakımından teminat yükümlülüğü altında bulunan kişi (garantör) ile ilgili olarak bildirim yükümlülüğü çerçevesinde değerlendirme yapmamak gerekir. Bu durumda sorunu, **bir başkasının icraî davranışla işlediği suçta ihmalî davranışla iştirak** bağlamında değerlendirmek gerekir.

Buna karşılık, **icrası devam etmekte olan bir suçla ilgili olarak**, kişinin suçun işlenmesini önleme (teminat) yükümlülüğünün bulunmamasına rağmen, **bildirim yükümlülüğü** söz konusu olabilir.

Örneğin, A, kaçak elektrik kullanmaktadır. Durumdan haberdar olan komşu B'nin, A'nın bu suçu işlemesini önlemek için müdahalede bulunma yükümlülüğü yoktur. Ancak B, işlenmekte olan bu hırsızlık (karşılıksız yararlanma) suçu ile

görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak “**öğrenil**”mesi gerekmektedir. Bu husus, hem söz konusu suç tanımına ilişkin madde metninde hem de gerekçesinde açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Aynı şekilde, TCK'nın 280. maddesinde tanımlanan **sağlık mesleği mensubu kişilerin suçu bildirmeme suçu** bakımından manevî unsur olarak **doğrudan kastın** varlığı şarttır. Çünkü bu suç tanımına ilişkin madde gerekçesinde işlendiği **öğrenilmiş** suçtan söz edilmektedir.

⁶⁴⁹ Yargıtay 5. Ceza Dairesinin **14.3.2016** tarihli ve E. 2014/899, K. 2016/2723 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Jandarma Karakol Komutanı olan S, köyde meydana gelen bir adli olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi vermez ve herhangi bir adli işlem yapmaz. Bu olayla ilgili olarak S hakkında soruşturma yapılır ve kamu davası açılır.

İlk Derece Mahkemesi, S'nin icraî davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini kabul ederek, TCK, m. 257, f. 1 hükmüne istinaden cezalandırılmasına hükmetmiştir.

Buna karşılık, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, **adli kolluk görevlisi** olan S'nin fiilinin, suçu bildirmeme suçunun TCK, m. 279, f. 2'de tanımlanan nitelikli halini oluşturduğu gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Ayrıca bkz. Yargıtay 5. CD, **11.5.2015**, E. 2015/10357, K. 2015/28737; Yargıtay 5. CD, **7.6.2016**, E. 2014/5514, K. 2016/5971; Yargıtay 5. CD, **11.7.2017**, E. 2014/9154, K. 2017/3099; Yargıtay 5. CD, 23.10.2017, E. 2017/3502, K. 2017/4499; Yargıtay 5. CD, **14.11.2019**, E. 2015/9191, K. 2019/10699; Yargıtay 15. CD, **2.7.2018**, E. 2018/3340, K. 2018/4899.

ilgili olarak bildirim yükümlülüğü altındadır. B tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, TCK'nın 278. maddesinde tanımlanan suç oluşturur (f. 1).

Baba ile oğlu, aynı apartmanın farklı dairelerinde otururlar. Oğul evine kaçak elektrik bağlar; baba, durumdan haberdar olmasına rağmen, bildirimde bulunmaz. Bu örnek olayda baba, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyi ihmal etmiştir. Ancak, baba ile oğlu arasındaki akrabalık (üstsoy-altsoy) ilişkisi, baba bakımından bir **şahsi cezasızlık sebebi** oluşturur.

Baba, üniversite öğrencisi olan oğlunun terör örgütü mensubu olduğunu bilir. Oğlu belirli aralıklarla dağa çıkarak örgütün eğitim programlarına katılır, örgüt tarafından verilen talimatları yerine getirir. Ancak, baba buna rağmen oğlu ile ilgili olarak bildirimde bulunmaz. Burada da, yukarıdaki elektrik hırsızlığı (karşılıksız yararlanma) örneğinde olduğu gibi, baba hakkında suç bildirmeme suçundan dolayı cezaya hükmetmemek gerekir.

TCK'nın 278. maddesinde tanımlanan suç bildirmeme suçunun konusunu, **icrası tamamlanmış** olmakla birlikte, **sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan suç** da oluşturabilir.

İcrası tamamlanmış olan bir suç bağlamında bu suçun işlenmesini önleme yükümlülüğünden artık söz edilemez. Çünkü bu durumda artık suç işlenmiş ve tamamlanmıştır. İşlenmiş olan bir suç işlenmemiş duruma irca etmek, geri döndürmek mümkün değildir.

İcrası tamamlanmış bir suçla ilgili olarak aile bireylerinin ve belirli bir akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişilerin ihbarda bulunmaması durumunda, **şahsi cezasızlık sebebi** söz konusudur (Any, m. 38, f. 5'e istinaden TCK, m. 278, f. 4).

Örneğin A hırsızlık suçundan elde etmiş bulunduğu bisikleti kullanmaya devam eder. Baba B, bu durumu öğrenir. Ancak, oğlu ile ilgili olarak hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle ihbarda bulunmaz.

XI. Herhangi bir kişi tarafından bir suçun işlenmekte olduğuna, işlenmeye devam edildiğine veya işlenmesine yönelik hazırlık yapıldığına kamu görevlisinin göreviyle bağlantılı olarak muttali olmasına rağmen, bu suçun işlenmesini önlememesi halinde ceza hukuku sorumluluğunu belirleme bir sorun oluşturmaktadır.

Bu durumda kamu görevlisini ihmalî davranışla işlenen görevi kötüye kullanma (TCK, m. 257, f. 2) suçundan dolayı sorumlu tutmak, akla gelebilir. Keza, bu durumda kamu görevlisinin suç bildirmemesi (TCK, m. 279) suçundan dolayı sorumluluğu düşünülebilir.

Görevi kötüye kullanma suçunun genel, talî ve tamamlayıcı bir suç olması dolayısıyla, bu suça ilişkin hükümler ancak kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesinin başka bağımsız bir suç oluşturmadığı hallerde uygulanabilecektir.⁶⁵⁰

⁶⁵⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *İrtikâp, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları*, 2. bası, Ankara, Haziran 2013, sh 149 vd.

Keza, önemle belirtmemiz gerekir ki, TCK, m. 279’da tanımlanan suçun oluşabilmesi için, kamu görevlisinin göreviyle bağlantılı olarak muttali olduğu suçun **icrası tamamlanmış** olan bir **suç** olması gerekir. Örneğin, sahte bir resmî belge düzenlendiğine kamu görevlisinin görevinin icrasıyla bağlantılı olarak muttali olmasına rağmen bu suçu bildirmemesi, TCK, m. 279’da tanımlanan suçu oluşturur. Bu itibarla, herhangi bir kişi tarafından **icrasına devam edilen bir suçun işlenmekte olduğuna** veya **işlenmesine yönelik hazırlık yapıldığına** göreviyle bağlantılı olarak muttali olan kamu görevlisi bakımından artık suçu bildirme yükümlülüğünden ziyade, **suçun işlenmesini önleme yükümlülüğünün** varlığını tartışmak gerekir.

Hemen belirtmek gerekir ki, **suçun işlenmesinin önleme yükümlülüğünün** mevcut olduğu durumlarda **icrasına devam edilen** veya **işlenmesine yönelik hazırlık yapılan suçla** ilgili olarak kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçuna ilişkin hükümler uygulanamaz. Bu durumda, şayet suçun işlenmesini önleme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak kanunlarda özel hükümlere yer verilmiş ise, bu hükümlerin uygulanması gerekir.

Örneğin, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı *Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu*na göre,

“Disipline aykırı gördüğü her hale müdahaleye ve emir vermeye her üst görevlidir.” (m. 24).

Keza,

“Her rütbe sahibi, kanunların, nizamların ve amirlerin kendisine tahmil ettiği bütün hizmet ve vazifeleri öğrenmeye, vazifeli olduğu yerlerde öğretmeye ve bu hizmet ve vazifeleri eksiksiz yapmaya ve takibederek yaptırmaya ve daima ve her yerde disiplini tesis ve muhafazaya ve maiyetini yetiştirmeye ve astın şahsi teşebbüsünü inkişaf ettirmeye ve kendisine teslim olunan silah, araç, gereç ve sair bütün askeri eşyayı, yapıları ve ağaçları ve hayvanatı korumaya memur ve mecburdur.” (TSK İç Hizmet K, m. 75).

Bu hükümler, **askeri hiyerarşide üst konumundaki kişiye, amir olsun veya olmasın, asker kişinin işlemekte olduğu suçu önleme yükümlülüğü** yüklemektedir. Söz konusu yükümlülüğün varlığı için, asker kişi tarafından işlenmekte olan suçun ağırlığının bir önemi bulunmamaktadır.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, işlenen suçtan dolayı sorumluluk rejimi, 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı *Askeri Ceza Kanununun* 139. maddesinde belirlenmiştir:

“Bir askeri karakolun veya bir müfrezinin veya hususi bir vazife ile mükellef olan bir kısım askerin kumandanı iken veyahut subaylarından veya nöbetçi iken mani olabileceği ve vazifeten men’e mecbur bulunduğu bir suçun yapılmasına göz yumarsa fîli kendisi yapmış gibi ceza görür.”

Buna göre, asker kişi, amir veya üst konumunda olması ya da nöbetçi olması dolayısıyla önlemek yükümlülüğü altında olduğu ve önleyebileceği bir suçun işlenmesine muttali olmasına rağmen, işlenmekte olan suç önlemekte ihmal göstermesi halinde, bu suçun **faili** olarak cezalandırılacaktır.

Söz konusu hükmün uygulanabilmesi için, birinci koşul, asker kişi tarafından işlenmekte olan bir suçun varlığıdır. Başka bir ifadeyle, **asker kişi tarafından icrası devam eden ve işlenmesi henüz tamamlanmamış olan bir suç** söz konusu olmalıdır.

İkinci koşul, asker kişinin bu **suçun işlenmesini önleme (teminat) yükümlülüğünün** olması gerekir. Bu yükümlülük, TSK İç Hizmet Kanununa göre (m. 24, 75), amir konumunda olsun veya olmasın **üste** terettüp etmektedir. Ancak, Askeri Ceza Kanunu, söz konusu yükümlülüğü, bir askeri karakolun veya müfrezenin subaylarına ve hatta nöbetçi askerlere de teşmil etmektedir (m. 139).

Üçüncü koşul, üstün asker kişi tarafından **işlenmekte olan bir suçun varlığını bilmesi, yani kastının olması** gerekir. Başka bir ifadeyle üst, somut bir suçun asker kişi tarafından **işlenmekte olduğu bilgisine muttali olmalıdır**.

Dördüncü koşul, işlenmekte olan suç önleme yükümlülüğü altında olan **üstün** fiilen bu **suçun işlenmesini önleme imkanının** olması gerekir. Şayet üst, işlenmekte olan suçun önlemeye fiilen muktedir değilse, **kusuru olmadığı için**, işlenen suçtan dolayı sorumlu tutulmaz. Üst bir şekilde hürriyetinden yoksun bırakılmış olmakla, işlenmekte olan suç önleme imkanını kaybetmiş olabilir.

Ancak belirtmek gerekir ki, asker kişinin suçun işlenmesine engel olmaya ve bu çerçevede durumdan ilgili mercileri haberdar etmeye çalışması halinde herhangi bir kötülükle karşı karşıya kalmak tehlikesinin bulunması ya da **tehdit** edilmiş olması, söz konusu suçun önlenmesine yönelik girişimde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından bir **mazeret sebebi oluşturmaz**. Çünkü asker kişiler, TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre kendilerine terettüp eden görevleri yerine getirme uğruna, gerektiğinde “*seve seve hayatımı feda etmeme*”meyi kabul etmiştir (TSK İç Hizmet K, m. 37).

Keza, asker kişinin herhangi bir sebeple izinli olması ve birliğinin dışında bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi bakımından bir mazeret sebebi oluşturmaz.

Beşinci koşul, yukarıda sayılan dört koşulun varlığına rağmen üst, işlenmekte olan **suçun icrasını önlemeyi ihmal** etmiş olmalıdır.

Bu durumda üst, asker kişinin işlemekte olduğu suçun işlenişine ihmali davranışla iştirak etmiş olmaktadır ve bu suçun işlenmesinden dolayı (müşterek) **fail** sıfatıyla sorumlu tutulacaktır. Asker kişinin işlemekte olduğu suç, icraî bir suç

olmasına rağmen, bu suçun işlenmesini önlemeyi ihmal eden üst de söz konusu suçtan dolayı **müşterek fail** sıfatıyla cezalandırılacaktır.^{651,652}

Bir başkasının işlemekte olduğu icraî suça ihmalî davranışla iştirakten dolayı sorumluluk için en önemli koşul, **suçun işlenmesini önleme** yönünde **teminat yükümlülüğünün** bulunmasıdır. Suçun işlenmesini önlemekle yükümlü olan kişi, bir başkası tarafından icraî davranışla işlenen suçun işlenmesini önlemediği takdirde, kural olarak, bu suça şerik sıfatıyla iştirakten dolayı sorumlu tutulur. Ancak, kanunda suçun işlenmesini önleme (teminat) yükümlülüğü altında bulunan kişinin bir başkası tarafından icraî davranışla işlenen suçun işlenmesini önlemediği takdirde bu suçtan fail sıfatıyla sorumlu tutulması gerektiği ya da suçun ihmalî davranışla da işlenebildiği hususunda açık hüküm bulunan hallerde, failliğin şerikliğe nazaran asliliği kuralı gereğince kişiyi, işlenen bu suçun müşterek faili olarak sorumlu tutmak gerekir. Bir başka ifadeyle, sadece teminat yükümlülüğünün varlığı, bir başkası tarafından icraî davranışla işlenen suçun işlenişine ihmalî davranışla iştirak eden kişinin bu suçtan müşterek fail sıfatıyla sorumlu tutulmasını sağlamamaktadır. Bu konuda kanunda açık hüküm bulunması gerekir.

Keza, gümrüklerden mal giriş ve çıkışlarını kontrol etmek, Ticaret Bakanlığının ve bu amaçla söz konusu Bakanlık bünyesinde oluşturulan bir birim olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görevidir.⁶⁵³ Bu kontrol görevi, ilgili kamu görevlileri bakımından gümrük kaçakçılığı fiillerinin, kaçakçılık suçlarının işlenmesini önleme yükümlülüğünü ifade etmektedir. Kaçakçılık suçlarının işlenmesini önlemekle yükümlü olan kamu görevlisi, bir kaçakçılık fiilinin işlenmesine yönelik hazırlık yapıldığına veya icra hareketlerine muttali olmasına rağmen, bu suçun işlenmesini önleme yönünde gerekli girişimlerde bulunmadığı takdirde, başkaları tarafından işlenen kaçakçılık suçuna ihmalî davranışla iştirak etmiş olur. Kaçakçılık suçunun ihmalî davranışla işlenmesi hususunda kanunda açık hüküm bulunduğu için, bu kamu görevlisi **müşterek faili** olarak sorumlu tutulacaktır (21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı *Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu*, m. 4, f. 6).

Suçun işlenmesini önleme (teminat) yükümlülüğünün varlığına rağmen, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu ile ilgili olarak kanunlarda özel hüküm bulunmayan durumlarda, şayet hazırlık hareketlerine muttali olunan suçun icrasına başlanmış ise, **icraî davranışla işlenen su-**

⁶⁵¹ Yargıtay 16. CD, **14.7.2017**, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 36.

Önemle belirtmemiz gerekir ki, TCK'nın 309, 311 ve 312. maddelerinde tanımlanan suçlar ihmalî davranışla işlenemezler. Ancak icraî davranışla işlenebilen bu suçların işlenişine ihmalî davranışla iştirak edilebilir ve hatta, bu suçların işlenişine ihmalî davranışla iştirak eden kişi müşterek fail sıfatıyla sorumlu tutulabilir. Bu iki farklı durum, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin söz konusu kararında birbirine karıştırılmıştır (sh. 4).

⁶⁵² Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Örgütleri*, 13. bası, Ocak 2020, sh. 341 vd.

⁶⁵³ Bila tarihli ve 1 sayılı *Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi*, m. 441, f. 1, bent e, f, h; m. 449.

ça ihmalî davranışla iştirak eden teminat yükümlüsünü bu suçun işlenişine şerik sıfatıyla iştiraktan dolayı sorumlu tutmak gerekir.⁶⁵⁴

⁶⁵⁴ Anayasa Mahkemesinin 30.6.2011 tarihli ve E. 2010/52, K. 2011/113 sayılı Kararının (RG: 15 Ekim 2011/28085) konusunu oluşturan TCK, m. 278 hükümlerinin uygulandığı olayda, bir aile içerisinde kardeşlerden A ve B, henüz 15 yaşını doldurmamış olan diğer kardeş C'yi müteaddit defa cinsel yönden istismar ederler.

Anne, bu suçun müteaddit defa **işlenmekte** olduğundan haberdar olmasına rağmen, kızı C'yi oğulları A ve B'nin bu istismar fiilinden korumaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmaz.

Bu olay dolayısıyla kardeşler A ve B hakkında, C'ye karşı **cinsel istismar suçunu** (TCK, m. 103) **müteselsilen** (TCK, m. 43, f. 1) işledikleri iddiasıyla kamu davası açılır. Bunun yanı sıra, anne hakkında da **suçu bildirmeme suçundan** dolayı TCK, m. 278'de tanımlanan suç işle-diğinden bahisle kamu davası açılır.

Bu olay bağlamında **üç soruna** açıklık getirmek gerekir.

Birinci sorun, bir başkasının işlemekte olduğu **icraî suça ihmalî davranışla iştirakin** mümkün olup olmaması sorunudur.

İkinci sorun, **failliğin şerikliğe nazaran aslîliği kuralının** uygulanabilirliği sorunudur.

Nihayet **üçüncü sorun** ise, TCK'nın 278. maddesi hükümlerinin hangi koşullarda uygulanabilir olduğu sorunudur.

Bir başkası tarafından işlenmekte olan suçun işlenmesini önleme bakımından **teminat yükümlülüğü altında bulunan kişi** (garantör), bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmemek suretiyle, başkası tarafından icraî davranışla işlenen suçun işlenmesine ihmalî davranışla iştirak etmektedir. suçun işlenmesini önleme (teminat) yükümlülüğü altında bulunan kişinin bir başkası tarafından icraî davranışla işlenmekte olan suçun işlenişine kayıtsız kalması halinde, işlenmekte olan icraî suça ihmalî davranışla iştirak söz konusudur ve bu suçtan dolayı kural olarak **şerik (yardım eden)** sıfatıyla sorumluluğu gerektirir (JESCHECK, Hans Heinrich: *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, Berlin, 1988, sh. 548, 618, 630, dn. 55).

Ancak, izah ettiğimiz gibi, suçun işlenmesini önleme (teminat) yükümlülüğünün varlığının yanı sıra, kanuni düzenlemesi itibarıyla ilgili suçun ihmalî davranışla işlenmesinin fail sıfatıyla ceza sorumluluğunu gerektirdiği hallerde, **failliğin şerikliğe nazaran aslîliği kuralı** gereğince, teminat yükümlüsü, bir başkasının işlemekte olduğu suçun işlenişine engel olmadığı takdirde, bu suçtan dolayı **fail** sıfatıyla sorumlu tutulacaktır.

Örneğin, baba 15 yaşındaki çocuğunu eve hapseder. Çocuk, aylarca evden dışarı çıkamaz. Anne, bu durumdan haberdardır ve çocuğun bu durumdan kurtarılması için herhangi bir girişimde bulunmaz. Baba gibi annenin de çocuk üzerinde velayet ilişkisinden kaynaklanan **bakım ve gözetim yükümlülüğü** bulunmaktadır (Bkz. 4721 s. Türk Medeni Kanunu, m. 335 vd.). Bu bakım ve gözetim yükümlülüğü, **çocuğa karşı işlenmekte olan bir suçun işlenmesini önleme yükümlülüğü**nü de ifade etmektedir. Bu yükümlülüğün yanı sıra, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun kanuni tanımı itibarıyla annenin, baba tarafından çocuğuna karşı **işlenmekte olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna** (TCK, m. 109) ihmalî davranışla **iştiraktan** dolayı **fail** sıfatıyla sorumlu tutulması gerekir.

Buna karşılık, diğer bir örnekte, baba çocuğunu zincirleme şekilde cinsel yönden istismar eder. Anne, bu durumdan haberdar olmasına rağmen, çocuğun bu cinsel istismarının önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmaz. Bu durumda anne, babanın müteselsilen **işlemekte olduğu cinsel istismar suçuna** (TCK, m. 103) ihmalî davranışla **iştirak** etmiştir ve çocuğun cinsel istismarı suçunun kanuni tanımı itibarıyla bu suçtan dolayı ancak **yardım eden** sıfatıyla sorumlu tutulacaktır.

Anayasa Mahkemesinin kararının ilişkin olduğu olayda, kardeşler A ve B tarafından henüz 15 yaşını doldurmamış olan diğer kardeş C'ye karşı **müteselsilen işlenmekte olan bir cinsel istismar suç** (TCK, m. 103) söz konusudur. Anne, bu durumdan haberdardır ve çocuğun bu cinsel istismarının önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmaz. Bu durumda anne, A ve B'nin müteselsilen **işlemekte olduğu cinsel istismar suçuna** (TCK, m. 103) ihmalî davranışla **iştirak**

Keza, kolluk görevlileri, önleyici kolluk görevinin gereği olarak, suç işlenmesini önlemekle yükümlüdür (2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, m. 1). Bu itibarla, kolluk görevlisi, işlenişine, işlenmekte olduğuna muttali olmasına rağmen, bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmediği takdirde, görevi kötüye kullanma suçundan dolayı değil, işlenmesini engellemediği suçtan dolayı sorumlu tutulur. Bu durumda ilgili suça ilişkin kanuni düzenlemeler göz önünde bulundurularak, kolluk görevlisinin, bir başkası tarafından icraî davranışla işlenen suçun (müşterek) faili olarak ya da şeriki sıfatıyla sorumlu tutulması gerekir. Kolluk görevlisi, örneğin bir başkası tarafından icraî davranışla işlenmekte olan kasten öldürme, kasten yaralama veya işkence suçunun işlenişini önlemeyi kasten ihmal ettiği takdirde, bu suçların işlenişine ihmalî davranışla iştirak etmiş olur. Kasten öldürme ve kasten yaralama ve işkence suçlarının ihmalî davranışla işlenmesine ilişkin olarak Kanunda açık hükümler bulunması (TCK, m. 83, m. 88, m. 95, f. 5) karşısında, bu suçların **müşterek faili** sıfatıyla sorumlu tutulur.^{655,656,657} Buna karşılık, örneğin hırsızlık veya yağma suçunun işlenmekte ol-

etmiştir ve söz konusu suça **yardım eden** sıfatıyla iştirakten dolayı sorumlu tutulmalıydı. Bu nedenle, söz konusu olayda annenin sorumluluğunun TCK'nın 278. maddesinde tanımlanan suçta bildirmeme suçu bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutulması doğru olmamıştır.

Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *İcraî Suça İhmalî Davranışla İştirak, Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler*, in: Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, cilt 2, sayı 1-2, yıl 2014, sh. 1 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Örgütleri*, 13. bası, Ocak 2020, sh. 230, dn. 7, 8, 9, 10.

⁶⁵⁵ KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan: *Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler*, 7. bası, Ankara, Ekim 2020, sh. 149.

⁶⁵⁶ Kamu görevlisinin işlemekte olduğu **zimmet** veya **irtikâp** suçunu bu kişinin üzerinde gözetim ve denetim yetkisini haiz olan kamu görevlisi tarafından önlenmemesi durumunda, **müşterek fail** sıfatıyla sorumluluk söz konusudur (TCK, m. 251, f. 1).

Keza, Kanunda özel hüküm bulunmamakla birlikte, kamu görevlisinin işlemekte olduğu **rüşvet** suçunu bu kişinin üzerinde gözetim ve denetim yetkisini haiz olan diğer bir kamu görevlisi tarafından önlenmemesi durumunda, bu kamu görevlisi bakımından, teminat yükümlüsü olduğu için, bir başkasının **icraî davranışla işlemekte olduğu suça ihmalî davranışla iştirakten** dolayı, yani bu suçun işlenişine **fail** sıfatıyla iştirakten dolayı ceza hukuku sorumluluğu söz konusudur.

⁶⁵⁷ Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde bulunan bazı asker kişiler ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi birimlerin yönetim kadrosunda görev yapan belirli kişilerin 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe teşebbüsünün hazırlık ve icra hareketlerinin içinde bulunmamakla birlikte, bu suçun icrasına ilişkin hazırlık faaliyetlerinden haberdar olmalarına rağmen, bu kişiler tarafından söz konusu darbe teşebbüsünün icrasına başlanmasının engellenmesi yönünde uygun zamanda etkin bir girişimde bulunulduğu hususunda toplum bilgilendirilmiş değildir.

Söz konusu darbe teşebbüsünün hazırlık ve icra hareketlerinin içinde bulunan kişilerin ceza hukuku sorumluluğu, izahtan varestedir.

Sorun teşkil eden husus, söz konusu darbe teşebbüsünün hazırlık ve icra hareketlerinin içinde bulunmamakla birlikte, önemli kamusal görevlerde bulunan ve bu hazırlıklardan haberdar olan kişilerin, suçun icrasına başlanmadan önce ve suçun işlenmesini engelleyecek şekilde gerekli tedbirleri almamalarıdır.

Söz konusu darbe teşebbüsünün hazırlık hareketlerinin içinde bulunmamakla birlikte, bu hazırlıklardan haberdar olan ve fakat, suçun icrasına başlanmadan önce ve suçun işlenmesini

duğu bilgisine sahip olmasına rağmen, bu suçun işlenişini önlemeyi kasten ihmal eden kolluk görevlisini, bu suçlara şerik, **yardım eden** sıfatıyla sorumlu tutmak gerekir.

Aynı şekilde, belediye ve il özel idaresi gibi, imar uygulamalarının hukuk zemininde icrasını gözetlemek ve denetlemekle görevli kamu idarelerinin yetkilileri, kaçak yapılaşmayı önleme bakımından yükümlülük altındadırlar ve teminat yükümlüsüdürler. Bu itibarla, kaçak yapılaşmadan, imar mevzuatına ve imar planlarına aykırı olarak gerçekleştirilmekte olan yapılaşma faaliyetlerinden haberdar olan belediye ve il özel idaresi gibi kamu idarelerinin yetkililerinin, buna rağmen kaçak yapılaşmayı engelleme yönünde girişimde bulunmayı ihmal etmeleri halinde, örneğin TCK, m. 184'de veya 2863 sayılı *Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda* tanımlanan suçların işlenişinden dolayı **yardım eden** sıfatıyla sorumlu tutulmaları gerekmektedir.

XII. Yukarıda da belirtildiği gibi, TCK, m. 280'de tanımlanan **sağlık mesleği mensubu kişilerin suçu bildirmeme suçu** bakımından manevi unsur olarak **doğrudan kastın** varlığı şarttır. Bu itibarla, sağlık mesleği mensubunun **işlendiği hususunda kesin bilgi sahibi olduğu** bir **suçla** ilgili olarak ihbar yükümlülüğünün varlığından söz edilebilir. Buna karşılık, işlendiği hususunda sadece **kuşkun**un ortaya çıkması halinde, sağlık mesleği mensubu kişiler bakımından bildirim yükümlülüğü varlığını devam ettirmesine rağmen, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, TCK, m. 280'de tanımlanan suçu oluşturmaz.^{658 659}

engelleyecek şekilde gerekli tedbirleri almayan kamu görevlilerinin ceza hukuku sorumluluğunun gündeme getirilmemesi, hukuk uygulamamız bakımından önemli bir sorundur.

⁶⁵⁸ Bkz. ÖZGENÇ, İzzet: "Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğünün Kapsamı ve Sınırları", in: SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Aralık-Ocak-Şubat 2007-2008, sayı 5, sh. 84 vd.

⁶⁵⁹ Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 15.5.2014 tarihli ve E. 2013/16353, K. 2014/6220 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; 22 yaşında olan ve ileri derecede zekâ geriliği bulunan B, annesinin nezaretinde Devlet Hastanesine başvurur; kadın doğum hastalıkları uzmanı S tarafından muayene edilir ve 14 haftalık hamile olduğu tespit edilir. Bu hamileliğin, B'ye karşı işlenen cinsel saldırı suçu sonucu olduğu değerlendirilerek, S'nin TCK, m. 280'de tanımlanan suçu bildirmeme suçunu işlediği iddiasıyla hakkında kamu davası açılır.

İlk Derece Mahkemesi, sağlık görevlisi olan S'nin suçu (B'ye karşı işlenmiş olan cinsel saldırı suçu) bildirmeme suçunu işlediğini kabul ederek, 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezanın ertelenmesine hükmetmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin kararının gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

"Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunun düzenlendiği TCK madde 280'de geçen "belirti" kelimesinde kasıt, sağlık mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde kanaat uyandırmaya elverişli maddi emarelerle karşılaşmış olmasıdır. Belirtinin suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe oluşturacak mahiyette olması yeterlidir." (Tunceli Sulh CM, 20.11.2012, E. 2012/165, K. 2012/379).

Buna karşılık Yargıtay 9. Ceza Dairesi, düzenlenen epikriz raporunda B ile ilgili olarak "mental retardasyon" (zekâ geriliği) tanısının konulduğunun belirtmiş olmasına rağmen, S'nin B'ye

Önemle belirtmek gerekir ki, bir suç olgusuna dayalı yaralanmalarda bu sebeple sağlık kuruluşuna başvurulduktan bir müddet sonra ölüm gerçekleşmiş ise, **iki ayrı bildirim yükümlülüğü** söz konusudur. Bunlardan birincisi, vaki yaralanmanın bir suçtan kaynaklandığı hususuna ilişkin bilgi verme yükümlülüğüdür;⁶⁶⁰ ikincisi ise, yaralanan kişinin tedavi sürecinde bilahare öldüğü hususunda bilgi verme yükümlülüğüdür.⁶⁶¹

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin **25.11.2015** tarihli ve E. 2015/5251, K. 2015/4545 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; geçirdiği trafik kazası sonucu beyin travması yaşayan bebek A, ... Devlet Hastanesine kaldırılır. Bir süre tedavi gören A, tedaviye rağmen hastanede ölür. Hastane başhekimi S hakkında bu ölüm olayı ile ilgili olarak adli mercilere gerekli bildirimde bulunmadığı için soruşturma başlatılır ve kamu davası açılır.

“karşı cinsel saldırı suçunun işlendiğini bildiğine dair delil bulunmadığı” ve bu nedenle, hakkında “beraat kararı” verilmesi gerektiği gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin verdiği mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Bu karar, Yargıtay’ın, Türkiye’de aktüel bir sorun olan ileri derecede zekâ geriliği bulunan kişilerin çoğu zaman aile içinde cinsel yönden maruz kaldıkları istismarı ve buna bağlı olarak kalınan gebelikler sorununu görmezlikten gelme eğiliminin bir göstergesidir. Bu eğilimin bariz bir şekilde görüldüğü kararlardan birini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **28.2.2019** tarihli ve E. 2017/648, K. 2019/145 sayılı Kararı oluşturmaktadır.

Oysa zekâ geriliği bulunan kişilerin, kanuni temsilcilerinin gözetim ve denetim görevlerini layıkıyla yerine getirmemesinden istifade edilerek, farklı kişiler tarafından cinsel yönden istismar edilmeleri ve bu istismarlara bağlı olarak kimden kalındığı tespit edilemeyen hamileliklerin oluştuğu, gerçektir. Hatta, bu istismarların önemli bir kısmının ensest ilişki şeklinde tezahür ettiği, göz ardı edilmemelidir.

Bu istismarlara bağlı olarak hamile kalınan çocuğun dünyaya getirilmesi, bu çocuğun baba yönünden nesep bağı, bu çocuğun bakım ve gözetiminin yerine getirilmesi sorunları, Yargıtay’ın bu tutumu nedeniyle ki, çözümsüz kalmaktadır. Hukuk zemininde bu sorunlara çözüm oluşturulmaması, kişileri maddi gerçekliğin üzerinin küllenmesini sağlamaya yönelik fiili “çözüm” arayışlarına sevk etmektedir.

Aynı sorun, **çocuk hamilelikler**le ilgili olarak da yaşanmaktadır.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinin **14.1.2020** tarihli ve E. 2019/301, K. 2020/13 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, ... Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta olarak başvuran çoğu yabancı uyruklu olan, önemli bir kısmı henüz **on beş yaşını tamamlamamış çok sayıda çocuğun hamile olduğu, hamilelik geçirdiği** tespit edilmesine rağmen, adli mercilere gerekli bildirimde bulunulmaz.

İlk Derece Mahkemesi, bu olayla ilgili olarak sanıkların BERAATİNE hükmetmiştir.

İşbu çalışmanın yapıldığı sırada henüz kanun yolu incelemesi aşamasında olduğu için, bu “beraat” kararı ile ilgili olarak hukuki değerlendirme yapılmamıştır.

Dikkat edilmelidir ki, evli olmayan çocuk hamilelerle ilgili olarak, yaşları ne olursa olsun, on beş yaşın üzerinde olsalar bile, bildirim yükümlülüğü mevcuttur (Bkz. Yargıtay 11. CD, **13.11.2018**, E. 2017/13383, K. 2018/9025. Ancak belirtmek gerekir ki, Dairenin bu kararı, başta tabibin kastına ilişkin sübut sorunu olmak üzere, pek çok yönden hukuken sorunludur).

⁶⁶⁰ Bu yükümlülüğün hukuki dayanağı, TCK, m. 279 ve 280’dir.

⁶⁶¹ Bu yükümlülüğün hukuki dayanağı, CMK, m. 159 dur.

İlk Derece Mahkemesi, S hakkında sağlık mesleği mensubu olması sebebiyle TCK, m. 280, f. 1 hükmüne istinaden mahkûmiyet hükmü kurmuştur.

Buna karşılık, Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, S'nin *"bebeğin ölüm belgesinde başhekim olarak imzasının bulunması karşısında; CMK'nın 159. maddesi gereğince bildirim yükümlülüğünün ihlal edilmesi TCK'nın 257. maddesinde yazılı görevi ihmal suçunu oluşturabileceğinden bu suçun unsurlarının tartışılarak karar verilmesi"* gerektiği gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Hukuki değerlendirmemiz: Bebek A'nın yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup olmamasına göre değerlendirme yapmak gerekir. Bu çerçevede iki ihtimal düşünülebilir.

Birinci ihtimal: Meydana gelen trafik kazasına kolluk ve Cumhuriyet savcısı muttali olmuştur ve bu kaza dolayısıyla ilgililer hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bu durumda, söz konusu kazada yaralanan A'nın bilahare ölmesi üzerine gerekli bildirimde bulunulmaması, TCK, m. 279 ve 280. maddelerde tanımlanan suçu bildirmeme suçunu oluşturmaz. Bu durumda, hastane yönetimi tarafından söz konusu soruşturmanın yürütüldüğü Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma konusu trafik kazasında yaralanan A'nın ölmüş olduğunun CMK, m. 159 hükümlerine istinaden bildirilmesi gerekmektedir. Zira, her ne kadar adli merciler trafik kazasının gerçekleşmiş olduğu hususunda bilgilendirilmiş ve bu nedenle soruşturma başlatılmış ise de, bu kaza dolayısıyla ilgililerin ceza hukuku sorumluluğu bakımından kazada yaralanan kişilerin ölmüş olup olmaması önem taşımaktadır. Bu bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, **ihmalî davranışla işlenmiş görevi kötüye kullanma** suçunu (TCK, m. 257, f. 2) oluşturur.⁶⁶² Bu ihtimal bağlamında Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararı doğrudur.⁶⁶³

⁶⁶² Yargıtay 16. Ceza Dairesinin **6.10.2015** tarihli ve E. 2015/2673, K. 2015/3025 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan A, hastaneye kaldırılır. Acil servis görevlisi olan S, A ile ilgili olarak acil servis hasta tetkik defterine "adli vaka" kaydını düştükten sonra, A'yı yoğun bakım servisine yönlendirir. A, yoğun bakım ünitesinde ölür. Bu ölümle ilgili olarak kolluğa veya adli mercilere bilgi verilmez. Bu olay dolayısıyla acil servis görevlisi hakkında ölüm olayını bildirmemek dolayısıyla soruşturma başlatılır ve kamu davası açılır.

İlk Derece Mahkemesi bu olayda yoğun bakım servisinde yatmakta olan yaralı hastanın bu serviste ölmesinden dolayı acil servis görevlisinin bildirim yükümlülüğü bulunmadığı gerekçesiyle S hakkında beraat kararı verir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de bu kararı doğru bularak, onanmasına karar verir.

Hukuki değerlendirmemiz: Söz konusu kararda, kolluğun ve adli mercilerin muttali olduğu bir trafik kazasında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan A'nın tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bilahare ölmesi halinde, bu ölüm bildiriminin kimin tarafından yapılması gerektiği sorunu ortaya çıkmıştır.

⁶⁶³ Ancak, belirtmek gerekir ki, Yargıtay'ın bazı kararlarında bu iki yükümlülük birbirine karıştırılarak, aralarındaki fark göz ardı edilerek değerlendirme yapılmıştır. Yargıtay 9. CD, **20.1.2014**, E. 2013/11235, K. 2014/745; Yargıtay 8. CD, **25.9.2017**, E. 2017/8520, K. 2017/10257.

İkinci ihtimal: Meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak kolluğa veya adli mercilere bildirimde bulunulmamıştır. Bu kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılmıştır. Bazı durumlarda, yaralanan da dahil olmak üzere, kişiler gerçekleşen trafik kazasını saklı tutmak isteyebilirler; durumdan ilgili mercilerin haberdar olmasını istemeyebilirler. Bu nedenledir ki, yaralı vaziyette kişiler bir sağlık kuruluşuna götürüldüklerinde, şayet vaki yaralanma bir trafik kazasına bağlı veya bıçakla ya da sair silahla yaralanma kuşkusu oluşturuyorsa, kamu görevlisi olsun veya olmasın, duruma muttali olan sağlık görevlisinin bu durumla ilgili olarak kolluğu veya adli mercileri bilgilendirmesi gerekir. Sağlık görevlisi tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, suç olarak tanımlanmıştır.^{664,665} Bu durumda TCK'nın 279 ve 280. maddelerinde tanımlanan suçlardan hangisinden dolayı cezaya hükmetmek gerektiğini, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen sağlık görevlisinin aynı zamanda kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşıyamamasına göre belirlemek gerekir. Şayet bu sağlık görevlisi aynı zamanda bir kamu görevlisi ise, yani kamu kurumu niteliğindeki herhangi bir sağlık kuruluşu (Devlet veya üniversite hastanesi) çalışanı ise, TCK, m. 279'da tanımlanan suçtan dolayı cezai sorumluluk yoluna gidilmesi gerekir.⁶⁶⁶ Aksi takdirde, yani bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen sağlık çalışanının aynı zamanda kamu

⁶⁶⁴ Yargıtay 8. CD, **12.3.2020**, E. 2018/4133, K. 2020/11496.

⁶⁶⁵ Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin suç oluşturabilmesi için, yaralanma veya ölümün bir adli vakadan kaynaklandığının **bilinmesi** gerekmektedir (Bu hususta bkz. Yargıtay 12. CD, **29.9.2016**, E. 2015/13264, K. 2016/11414). Yani suçu bildirmeme suçu, ancak **doğrudan kastla** işlenebilir.

Sağlık görevlisi, tıbbi müdahalede bulunduğu yaralı kişinin yarasının bir suçtan kaynaklandığı hususunda şüphelendiğinde de, durumu ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür. Ancak bu durumda, suç şüphesine rağmen bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, sadece disiplin sorumluluğunu gerektirir. Buna karşılık, kişinin yarasının suçtan kaynaklandığının şüphe götürmez bir şekilde öğrenilmesine rağmen, örneğin bıçak veya kurşun yarası gibi durumlarda, bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suç oluşturacaktır.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin **29.5.2014** tarihli ve E. 2013/16509, K. 2014/6524 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; trafik kazasında yaralanan A, başvurduğu hastanede kendi kendini yaraladığı yönünde beyanda bulunur. A'nın trafik kazasında yaralandığının anlaşılması üzerine, sağlık görevlisi S hakkında suçu bildirmeme suçundan dolayı soruşturma başlatılır ve kamu davası açılır.

İlk Derece Mahkemesi, S'nin suçu bildirmeme suçunu işlediğini kabul ederek, hakkında TCK, m. 280 hükümlerine istinaden cezaya hükmetmiştir.

Buna karşılık, Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise, S'nin "yüklenen suçtan mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği" ve bu nedenle hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

⁶⁶⁶ Bkz. Yargıtay 4. CD, **17.12.2012**, E. 2012/13441, K. 2012/30482; **15.12.2010**, E. 2010/10480, K. 2010/20911; Yargıtay 9. CD, **15.5.2014**, E. 2013/16353, K. 2014/6220. Ancak, Yargıtay'ın farklı kararlarında, failin kamu görevlisi sıfatını taşıyan sağlık görevlisi olması halinde de TCK, m. 280'de tanımlanan suç bağlamında ceza sorumluluğu değerlendirilmesi yapılmıştır: Yargıtay 9. CD, **29.5.2014**, E. 2013/16509, K. 2014/6524.

görevlisi sıfatını taşımadığı hallerde, TCK, m. 280’de tanımlanan suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir.⁶⁶⁷

XIII. TCK, m. 284, f. 1’de tanımlanan hükümlünün ya da hakkında tutuklama kararı verilmiş olan şüpheli veya sanığın saklandığı yerin bildirilmemesi suçu, gerçek ihmalî suç örneklerinden birini oluşturmaktadır. Söz konusu düzenlemeye göre, “*hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, ... cezalandırılır.*” Madde gerekçesinde bu suçla ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir: “*hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yerin ihbar edilmemesi, suçu ihbar etmemekten bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Belli bir suçun işlenmiş olması dolayısıyla başlatılan soruşturma ve kovuşturma kapsamında bu suçu işlediğinden bahisle hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kişinin bulunduğu veya saklandığı yerin yetkili makamlara bildirilmemesi, suç oluşturmaktadır.*

*Bunun için, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, soruşturma ve kovuşturma konusu yapılan suç dolayısıyla şüpheli bulunan şahıs hakkında tutuklama kararının verilmiş olduğunu veya kesinleşmiş bir yargı kararıyla belli bir cezaya mahkûm olmuş olan şahsın bu cezasının infazı amacıyla arandığını ve nerede bulunduğunu tereddütsüz bir şekilde bilmelidir. Başka bir deyişle, söz konusu suçu ancak **doğrudan kastla** işlenebilir.*”⁶⁶⁸

284. maddenin birinci fıkrasındaki tanım itibarıyla, söz konusu suç ancak tutuklandıktan sonra kaçan şüpheli veya sanığın saklandığı yerin bildirilmemesi halinde oluşabilecektir.⁶⁶⁹

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu suç, **ihmalî** bir suçtur. Hakkında tutuklama kararı verilmiş olmakla birlikte kaçmış veya henüz yakalanmamış şüpheli veya sanığın ya da hakkında hapis cezasına hükmedilmiş ve cezası kesinleşmiş olmasına rağmen bu cezanın infazından kaçan hükümlünün saklandığı yerin bildirilmemesi, söz konusu suçu oluşturur. **Gerçek ihmalî suç.**⁶⁷⁰ Kaçan şüpheli sanık veya hükümlünün bilahare yakalanmış olması, bu suçun oluşmasına engel teşkil etmez.

⁶⁶⁷ Yargıtay 4. CD, **19.1.2015**, E. 2014/8297, K. 2015/1500.

⁶⁶⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 674 vd.

⁶⁶⁹ “Suç Örgütleri” kitabımızda, hakkında yakalama kararı verilen kişilerle ilgili olarak da söz konusu suçun oluşabileceği yönünde görüş dermeyeran edilmisti (13. bası, sh. 229, dn. 6). Ancak, kıyas yasağının gereği olarak, bu görüşümüzü değiştirmiş bulunmaktayız.

⁶⁷⁰ Yargıtay 16. Ceza Dairesi, hakkında mahkûmiyet hükmü bulunan X’i “**evinde saklayan**” Y’nin, “*araştırma veya yakalanmadan kurtulması için imkân sağladığına dair mahkûmiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilmeden yüklenen suçtan beraat*” etmesi gerektiği gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesi tarafından TCK, m. 283’de tanımlanan suçun oluştuğu kabul edilerek kurulan mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir (Yargıtay 16. CD, **17.6.2015**, E. 2015/1098, K. 2015/1794).

Söz konusu suçun faili herkes olabilir. Ancak, suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir (m. 284, f. 3).⁶⁷¹

Buna karşılık aynı Daire, “*hakkında kasten öldürme suçundan yakalama kararı olan X’in içinde bulunduğu, yolda kalan aracı, kendi yönetimindeki araç ile çekerek kurtar*”an Y’nin “*suç işleyen kişiye araştırmadan kurtulması için imkân sağlama mahiyetinde olan eyleminin, TCK’nın 283/1. maddesinde tanımlanan ‘suçluyu kayırma’ suçunu oluşturacağı*” yönünde içtihatla bulunmuştur (Yargıtay 16. CD, 17.6.2015, E. 2015/1098, K. 2015/1794).

⁶⁷¹ Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 14.11.2011 tarihli ve E. 2009/19013, K. 2011/21017 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûmiyet hükmü bulunan A, Almanya’dan Türkiye’ye gelerek avukat B ile görüşür. B, A’ya, İnfaz Kanunu’nun 75 yaşını doldurmuş olan hükümlünün mahkûm olduğu belirli bir süreyi aşmayan hapis cezasının infaz kurumunda değil evinde çektirileceği yönündeki düzenlemesinden bahisle, yaş tashihi davası açarak sorunu halledebileceği vaadiyle, cezasının infazı için teslim olmaması önerisinde bulunur. A, bu öneriye itibar ederek teslim olmaz. B, A ile ilgili olarak Aybastı Asliye Hukuk Mahkemesinde yaş düzeltme davası açarsa da bu dava reddedilir; bunun üzerine, Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesinde ikinci bir yaş düzeltme davası açar. Bu dava görülmeğe devam ederken, A yakalanır ve cezasını çekmek üzere infaz kurumuna yerleştirilir.

Bu olayla ilgili olarak B hakkında açılan kamu davasında, İlk Derece Mahkemesince, TCK, m. 284, f. 1’de tanımlanan **hükümlünün saklandığı yeri bildiği halde yetkili mercilere bildirimde bulunmama suçundan** dolayı mahkûmiyet hükmü kurulmuştur.

Buna karşılık, Yargıtay 4. Ceza Dairesi, aşağıya iktibas edilen, B’nin fiilinin görevi kötüye kullanma suçu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle, hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir:

“*Avukat ile müvekkili arasındaki sözleşme ilişkisinin temeli güven ve sadakat ilkelerine dayanmaktadır. Müvekkilin; her durumda avukatına güvenmesi, sırrını saklayacağından emin olması gerekir. Bu nedenle Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesinde, avukatların görevlerini “bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmakla” yükümlü oldukları ifade edilmiş ve Yasa’nın 36. maddesinde de görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açıklamaları yasaklanarak sır saklama yükümlülükleri öngörülmüştür.*

Avukatın, müvekkilinin sırrını saklama yükümlülüğü üçüncü kişiler yanında mahkemelere, savcılıklara ve idari birimlere karşı da geçerlidir. Avukatlık meslek sırrı, avukatın mesleğini icra ederken öğrendiği, herkes tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde vekil edenin maddi ya da manevi zarara uğrayacağı, üçüncü kişilerden gizlenen özel yaşama dair bilgilerdir. Avukatın mesleği ile bağlantılı olarak öğrendiği, vekil edene ait özel ilişkileri, sağlık bilgileri, mali durumu, kişisel bilgileri gibi gerektiğinde bulunduğu yer ya da adresi de sır kapsamına dahildir. Avukata yüklenen sır saklama yükümlülüğü, vekil edenin adli/idari merciler karşısında daha etkin, yerinde ve etraflıca iddida bulunması veya savunma yapması ile doğrudan bağlantılıdır. Avukatın meslek sırrını koruması ise uluslararası antlaşmalar ve Anayasamızda güvence altına alınan özel yaşamın gizliliğinin sonucu olmanın yanında yerine getirilen kamu hizmetinin içeriği ve niteliği ile de ilgilidir.

*Sanığın özgür iradesiyle seçeceği bir avukatın yardımından yararlanmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c, Anayasamızın iddia, savunma ve adil yargılanma hakkını öngören 36, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun dürüstlük ve güven ilkelerini öngören 34 ve avukatın sır saklama yükümlülüğünü düzenleyen 36. maddelerindeki düzenlemeler dikkate alındığında sanık avukatın, hakkında yakalama kararı bulunan vekil edenin yerini adli mercilere bildirmemesinin **sır saklama yükümlülüğü** ile bağlantılı olarak TCK’nın 24/1. maddesi anlamında **kanunun hükmünü (görevini) yerine getirme hukuka uygunluk nedeni** olarak değerlendirilerek CMK’nın 223/2-d maddesi gereğince anılan suçun oluşmayacağı kabul*

Buna karşılık, söz konusu suçun, belli akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişiler lehine olarak işlenmesi hâlinde, cezaya hükmedilmeyecektir (m. 284, f. 4). Kişinin önceden işlenmiş olan asıl suçun fail veya şerik ile belli akrabalık ilişkisi içinde bulunması, yani söz konusu suçun “*üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi*”, bu suç bakımından bir **şahsî cezasızlık sebebi** oluşturmaktadır.

XIV. TCK, m. 284, f. 2’de “Suç delillerini bildirmeme”, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır:

“İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği hâlde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, ... cezalandırılır.”

Madde **gerekçesinde** de açıklandığı üzere, “*işlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yerin bilinmesine rağmen, yetkili makamlardan durumdan haberdar edilmemesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.*”⁶⁷²

Bu suçun konusunu, **bir başkası tarafından işlenmiş olan** bir suça ilişkin delil ve eserler oluşturmaktadır. Kişinin kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suça ilişkin delil ve eserlerin bulunduğu yerle ilgili olarak adli mercilere, mülki makamlara veya genel olarak kolluğa bilgi vermemesi, cezalandırılmamaktadır.⁶⁷³

Bu suç, **ihmalî** bir suçtur. Kişinin bir başkası tarafından işlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin saklandığı yerin bilmesine rağmen durumdan adli mercilere veya kolluğa bilgi verilmemesi ile söz konusu suç oluşur. Başka bir ifadeyle, muayyen bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun konusunu oluşturan

*edilmesi, ancak müvekkilinin infaz yönteminin değiştirilmesi amacıyla gerçeğe aykırı iddiaya dayanarak ve müvekkili hakkında daha önce benzer gerekçeyle Aybastı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1970/129 esas, 1970/66 sayılı kararı ile doğum yılının 1936 olarak düzeltilmiş olmasına karşın, bu kez de gerçekte 1931 doğumlu olduğundan bahisle dava açması ve Aybastı’da açılan davanın reddedilmesine karşın ikinci kez Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de açtığı davanın da haklı nedene dayanmadığı gerekçesiyle reddedildiği gözetilerek sanığın Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca görevini doğruluk ve onur içinde yerine getirmek yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmakla birlikte, TCY’nin 257/1. maddesindeki; **kamu zararına neden olma, kişilere haksız kazanç (doğrusu, menfaat) sağlama** biçimindeki **objektif cezalandırma şartlarının var olup olmadığının somut olaya özgü olarak tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi** gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle Yasa’nın 284/1, 3. maddesiyle hükümlülük kararı verilmesi,” hukuka aykırıdır.*

⁶⁷² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 674 vd.

⁶⁷³ Yargıtay 12. Ceza Dairesinin **4.7.2018** tarihli ve E. 2018/4115, K. 2018/7434 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; baba ve oğul A ve B’nin C’yi öldürdüğü iddiasıyla haklarında kamu davası açılır. İlk Derece Mahkemesi yaptığı yargılamada, kasten öldürme suçunun işlenişine iştirak etmediğini tespit ettiği A’nın, B tarafından işlenen kasten öldürme suçunun işlenmesinde kullanılan silahın evde saklandığını bilmesine rağmen, durumu ilgili mercilere bildirmemekle TCK, m. 284, f. 2’de tanımlanan suçu işlediğini kabul eder; ancak B ile arasındaki usul fûru (üst soy alt soy) ilişkisi sebebiyle, TCK, m. 284, f. 4 hükmüne istinaden, A hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verir. Doğru bulduğumuz bu karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanarak, kesinleşir.

ran ya da suçun işlenmesi suretiyle veya suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilen eşyanın saklandığı yeri bilmekle beraber, kişinin durumdan ilgili makam veya mercileri haberdar etmemesi halinde, TCK, m. 284, f. 2’de tanımlanan suç oluşur:⁶⁷⁴,⁶⁷⁵ **Gerçek ihmalî suç.** Bu delil ve eserlerin bilahare ortaya çıkarılmış olması, bu suçun oluşmasına engel teşkil etmez.

⁶⁷⁴ Bu itibarla, kişinin bir başkası tarafından öldürülenin cesedinin saklandığı yeri öğrenmesine rağmen ilgili mercilere bildirimde bulunmaması, TCK, m. 284, f. 2’de tanımlanan suç oluşur: Yargıtay 1. CD, **13.11.2019**, E. 2017/3654, K. 2019/4942.

Ancak Yargıtay, bir başka olayda TCK’nın 284. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan suçtan habersiz olarak içtihatla bulunmuştur:

“Sanıkların maktule ait cesedi olay yerinde görüp güvenlik güçlerine bildirmemekten ibaret olan eylemleri (ihmalî davranışın gerçekleştirildiği tarih) itibarıyla suç oluşturmadığından beraatlerine karar verilmesi gerekir...”: Yargıtay 1. CD, **7.3.2007**, 3829/1173 (Yasar/Gökcan/Artuç, TCK, VI, sh. 8057).

⁶⁷⁵ Yargıtay 8. Ceza Dairesinin **16.6.2020** tarihli ve E. 2018/2891, K. 2020/13398 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Turan, Ergin’e ait eve girerek, evdeki dizüstü bilgisayarı alır ve uygun bir yerde saklar. Bilahare Naci ve Bilal ile görüşerek bu bilgisayarı kendilerine satmak ister. Bunun üzerine Turan, Naci ve Bilal ile birlikte, bilgisayarı sakladığı yerde görmeye giderler. Ancak, Naci ve Bilal, beğenmedikleri için, bilgisayarı satın almazlar.

Bu olay dolayısıyla, Turan hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarını, Naci ve Bilal hakkında ise suç bildirmeme suçunu işledikleri iddiasıyla kamu davası açılır.

İlk Derece Mahkemesi, bu olayla ilgili soruşturma evresinde Naci ve Bilal’in hırsızlık suçunun işlenişine iştirak ettikleri şüphesine binaen şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmış olması dolayısıyla *“tanıklıktan çekinme haklarının bulunduğu”* gerekçesiyle, bu sanıklar hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı vermiştir.

Buna karşılık, Yargıtay 8. Ceza Dairesi, söz konusu *“olayda hırsızlık suçunun işlenmiş olduğu ve sınırlandırılabilir neticesinin kalmadığı”* ve bu nedenle, TCK, m. 278’de tanımlanan suç bildirmeme suçunun oluşmadığı ve sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin verdiği *“ceza verilmesine yer olmadığına”* dair hükmü hukuka aykırı bulmuştur.

Hukuki değerlendirmemiz: Karara konu teşkil eden olayda, Turan tarafından işlenmiş olan hırsızlık suçu tamamlanmıştır. Bu durum karşısında, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan eşyanın saklandığı yeri bilahare öğrenen kişiye **bildirim yükümlülüğü** yüklemektedir. Bu yükümlülük, gerek TCK, m. 278’de tanımlanan **suçu bildirmeme** gerek TCK, m. 284, f. 2’de tanımlanan **suç delillerini bildirmeme** suçlarına ilişkin hükümlerle ihdas edilmiştir.

Ancak, hukuk sistemimiz, hırsızlık suçunun işlendiğini ve bu suçun konusunu oluşturan eşyanın saklandığı yeri bilahare öğrenen kişiye **bildirim yükümlülüğü** yüklemektedir. Bu yükümlülük, gerek TCK, m. 278’de tanımlanan **suçu bildirmeme** gerek TCK, m. 284, f. 2’de tanımlanan **suç delillerini bildirmeme** suçlarına ilişkin hükümlerle ihdas edilmiştir.

Karara konu teşkil eden olayda, suç bildirmeme suçunun değil, **suç delillerini bildirmeme suçunun** oluştuğunu kabul etmek gerekirdi.

Ancak, bazı durumlarda hem suç bildirmeme suçunun hem de suç delillerini bildirmeme suçunun oluşabilmesi mümkündür. Bu gibi durumlarda, **farklı neviden fikri içtima** (TCK, m. 44) hükümlerinin uygulanması yoluna gitmek gerekir. Ancak, burada dikkat edilmesi gerekir ki, her iki suçun cezasının aynı olması dolayısıyla, mahkemenin bu suçlardan herhangi birine istinaden cezaya hükmetmesi mümkündür.

Söz konusu olay sebebiyle yapılan soruşturmada Naci ve Bilal’in hırsızlık suçuna iştirak ettikleri şüphesiyle şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmış olması ne suç bildirmeme ne de suç de-

Kişinin bir başkası tarafından işlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserleri **kendisinin saklaması halinde** ise, TCK'nın 284. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan suç değil, 281. maddesinde tanımlanan **suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu** oluşmaktadır. 284. maddenin ikinci fıkrasında ise, “*işlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği hâlde yetkili makamlara bildirmeyen*” kişinin cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu suç, madde gerekçesinde de açıklandığı üzere, “*ancak doğrudan kastla işlenebilir.*”⁶⁷⁶

Söz konusu suçun faili herkes olabilir. Ancak, suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir (m. 284, f. 3).

Buna karşılık, söz konusu suçun, belli akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişiler lehine olarak işlenmesi hâlinde, cezaya hükmedilmeyecektir (m. 284, f. 4). Kişinin önceden işlenmiş olan asıl suçun fail veya şerik ile aralarında belli akrabalık ilişkisinin bulunması, yani söz konusu suçun “*üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi*”, bu suç bakımından bir **şahsî cezasızlık sebebi** oluşturmaktadır.

lillerini bildirmeme suçu bakımından bu kişilerle ilgili olarak bir şahsî cezasızlık sebebi oluşur. Bu nedenle, İlk Derece Mahkemesinin bu kişiler hakkında vermiş bulunduğu “ceza verilmesine yer olmadığı”na dair hüküm, hukuka aykırıdır.

Keza, söz konusu olayda, suçu bildirmeme suçunun değil, suç delillerini bildirmeme suçunun işlenmiş olması dolayısıyla, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Naci ve Bilal ile ilgili olarak beraat kararı verilmesi yönündeki kararı da hukuka aykırıdır.

Aynı hatalı değerlendirme, Yargıtay 17. Ceza Dairesinin **6.2.2018** tarihli E. 2015/25779, K. 2018/1120 sayılı Kararında da mevcuttur.

⁶⁷⁶ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 674 vd.

Ş18. Kusurluluk

I. Normatif Bir Değer Yargısı Olarak Kusurluluk

Sorumluluğun temel şartı, insan davranışının iradî olarak gerçekleştirilmesidir. Bu itibarla, insan, iradî olarak gerçekleştirmediği fiil hukuka aykırı olsa bile, bu fiilden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. İşlediği fiil ile kişi arasındaki bağlantı, suç teşkil eden haksızlığın *manevi unsurunu* oluşturmaktadır.

Haksızlık teşkil eden bir fiilin işlenmesi halinde, bu haksızlığı gerçekleştiren kişinin şahsi özelliklerini dikkate almaksızın, bu fiil hakkında bir değerlendirme yargısında bulunmaktadır. Buna karşılık, kusur söz konusu olduğunda; gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla, bir insan olarak faili hangi şartlarda sorumlu tutabileceğimiz tetkik konusu edilmektedir. Bu konuda bir yargıya varabilmek için, işlenen fiilin (haksızlığın) hangi şartlarda gerçekleştirildiğinin araştırılması gerekir. Kısaca, kusur; gerçekleştirdiği haksızlıkla ilgili olarak faildeki *iradenin oluşum şartlarının*⁶⁷⁷ tespiti ve bu tespite binaen gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla failin şahsen muaheze edilmesi gerekip gerekmediği hususundaki *yargıyı* ifade etmektedir^{678,679}.

Kusurluluk, suç teşkil eden fiilin bir vasfı değildir. Kusur, haksızlık teşkil eden fiili gerçekleştiren şahsın bu fiili gerçekleştirmesi nedeniyle muaheze edilmesi gerektiği konusundaki yargıyı ifade etmektedir. Bu itibarla, kusur, işlediği haksızlıkla ilgili olarak fail hakkında bulunulan yargıdan ibarettir. Kusur, belli bir fiile ilişkin olarak fail hakkındaki yargı olduğuna göre; belli bir fiilden soyut olarak, kişinin sürdürdüğü hayat tarzı itibarıyla kusurlu olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Ancak, kişinin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar, gördüğü eğitim gibi hususların, işlediği fiile ilişkin kusurunun belirlenmesinde etkili olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Kusur, haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi hakkında bir muaheze yargısı olması nedeniyle; bir fiil, failinin kusuru olmadan işlense dahi, haksızlık ve dolayısıyla, suç vasfını muhafaza edecektir. Demek ki, işlediği fiil dolayısıyla failin kusurlu addedilmesi veya addedilememesi, bu fiilin suç vasfını haiz bir haksızlık olması üzerinde etki doğurmayacaktır. Bu itibarla, meselâ işlediği fiilin hukuki anlam muhtevasını

⁶⁷⁷ Maximen der Willensbildung.

⁶⁷⁸ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 363; AKBULUT, Genel Hükümler, 5. bası, sh. 222; GÖKTÜRK, Haksızlık Yanılgısının Ceza Sorumluluğuna Etkisi, sh. 23 vd; ÇINAR, Ön Kusurluluk sh. 42.

⁶⁷⁹ *Ozansü*'ya göre “kusur, failin özgür iradesiyle haksızlığı seçmiş olmasıdır.” (OZANSÜ, Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 32). Bu tanıma göre, haksızlık yönünde tercihte bulunmuş olmak *durumu*, kusuru ifade etmektedir. Bu tanımlama ile kusurluluğun, gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla kişi hakkında bulunulan kınanabilirlik yargısını ifade ettiği göz ardı edilmiştir. Ancak yazar bilahare yaptığı bir başka tanımla bu eksikliği bir ölçüde gidermiş bulunmaktadır: “kusur, akli olan süjenin, özgür bir biçimde haksızlığı seçmiş olması (ndan) *kaynaklanmaktadır*.” (OZANSÜ, Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 33)..

idrak edemeyecek derecede aklî bozuklukla malûl bir akıl hastasının bir insanı öldürmesi halinde, işlenen fiil bir suç teşkil etmektedir; ancak, failin kusur yeteneği olmadığı için, kusurundan bahsetmek mümkün olmayacaktır⁶⁸⁰. İşlenen fiil dolayısıyla failin kusurlu addedilmemesi halinde dahi; işlenen fiil, muayyen bir haksızlık ifade edebileceğine göre, ceza hukuku açısından önemi haizdir. Ancak, bu durumda faile uygulanacak müeyyide farklılık arzedecektir. Şöyle ki; suç teşkil eden muayyen haksızlığın işlenmesinden dolayı failin kusurlu bulunulması halinde, tatbik edilecek müeyyide, bir cezadır. Buna karşılık; failin kusur ehliyetinin bulunmaması veya genel olarak kusursuz olması halinde dahi, işlenen fiil, suç (haksızlık) vasfını muhafaza edecektir. Ancak, bu durumda faile tatbik edilecek müeyyide, bir ceza değil, güvenlik tedbiri olacaktır⁶⁸¹.

İşlenen fiilin bir haksızlık teşkil ettiği yargısına varılması, aynı zamanda failin de muaheze edilmesi gerektiği yargısını ihtiva etmez. İşlenen bu haksızlık nedeniyle failin muaheze edilip edilemeyeceği yargısına bilahare ayrıca varılmaktadır (kusurluluk yargısı). İşlenen fiilin bir haksızlık teşkil ettiği konusundaki yargıya varırken, failin bu fiil karşısındaki manevi durumunu da gözönünde bulundurmak gerekir. Yani, fail, prensip itibarıyla işlediği fiilin maddi unsurlarının şuurunda olmalıdır.

⁶⁸⁰ Ancak, ülkemizde ceza hukukçuları arasında hâlâ klasik suç teorisi etkisini devam ettirdiği için; bazı yazarlar tarafından suç teşkil eden fiilin manevî unsuru ile kusur, aynı kavramlar olarak mütalâa edilmektedirler (bkz. KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 90, 102; TOROSLU, Ceza Hukuku, sh. 43, 101/102). Bu anlayışın sonucu olarak şu fikirler ileri sürülmüştür:

“... her fiil, muhakkak kusurlu fiildir. Kusursuz fiil diye bir şey, ... mevcut olamaz” (KUNTER, Suçun Maddi Unsurları, sh. 8). “Hareket, kusurluluktan, yani manevî unsurdan müstakil olarak derpiş edilemez” (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 52). “Kusurluluk olmadan hukuka aykırılık bahis mevzuu” edilemez (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 97, ayrıca sh. 99, 101, 102).

“Kusurluluğu kaldıran sebeplerin mevcudiyeti halinde suçtan bahsedilemez” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 50). “Hukuka aykırı olup da kusurlu olmayan bir davranış mevcut olamaz” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 70). “Hukuka aykırılık, kusurluluktan müstakil olarak tahakkuk edemez” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 71). “Kusurluluk mevcut değilse, hukuka aykırılıktan bahsedilemez” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 74). “Hukuka aykırılıktan bahsedebilmek için failin isnad kabiliyetini haiz olması ve kusurlu hareket etmiş bulunması şarttır. ... (C)ezaî ehliyetini kaybetmiş ... bir şahıs, suç işleyemeyeceği gibi, hukuken önemi haiz bir fiil de işleyemez” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 84, 117).

⁶⁸¹ Ancak, Öztürk, suç teşkil eden fiiller ve “suça benzeyen ve fakat teknik anlamda suç olarak nitelenmeyen emniyet tedbirlerini gerektiren fiiller” olmak üzere bir ayırım yapmaktadır. Öztürk’e göre; “esas yaptırımı emniyet tedbiri olan fiillerin, günümüz suç genel teorisi çerçevesinde suç olarak nitelendirilmesi mümkün değildir”. Çünkü, “Ceza normunu anlayamayan, anlayabildiği halde ona uygun hareket edemeyen bir kimsenin hareketi teknik anlamda suç olarak nitelenemez” (ÖZTÜRK, Bahri: Ceza Muhakemesi Hukukunda Koğuşurma Mecburiyeti [Hazırlık Soruşturması], Ankara, 1991, sh. 3). Bu görüş, kanaatimizce, isabetli değildir. Çünkü, yukarıda da belirttiğimiz gibi, failin kusursuz olması halinde dahi işlenen fiil, suç (haksızlık) vasfını haiz olacaktır. Ancak, bu durumda faile tatbik edilecek müeyyide, ceza değil, tedbir olacaktır.

Kusur konusundaki bu anlayış, belli bir teorik gelişim süreci sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu süreçteki teorik görüşleri başlıca iki grupta toplayabiliriz⁶⁸². Bunlardan biri, *psikolojik teori*; diğeri ise, *normatif teori* adıyla anılmaktadır⁶⁸³.

Normatif bir perspektifle kusur, bir insanın işlediği haksızlık teşkil eden fiilden dolayı muaheze edilmesi gerektiği konusundaki yargıyı; bu fiile ilişkin iradenin oluşumunun kınanabilirliğini, muaheze edilebilirliğini ifade etmektedir⁶⁸⁴. Kusur yargısının ifade ettiği anlam şudur: Fail, hukuka uygun hareket etmemiştir; davranış normlarının icaplarına uygun hareket etme, haklı davranışı tercih etme imkân ve kabiliyetine sahip olmasına rağmen, haksız bir davranışta bulunmayı tercih etmiştir⁶⁸⁵. Kusur, böylece bir haksızlıkla bağlantılı olarak bu haksızlığı gerçekleştiren kişi hakkında bulunulan yargıdır⁶⁸⁶. Bir haksızlıktan mücerret, kişinin sürdürdüğü hayat tarzı itibarıyla, kişinin ahlâkî özellikleri itibarıyla kusurluluğundan bahsedilemez⁶⁸⁷.

Kusur yargısından önce, kanundaki muayyen suç tariflerine uygun bir haksızlığın gerçekleştirilmesi gerekir. Bu haksızlık kasten işlenmiş veya taksirle gerçekleştirilmiş bir haksızlık olabilir. Böylece, kast ve taksir, birer kusurluluk şekilleri olarak değil; haksızlığın birer gerçekleştiriliş şekilleri olarak, kısaca, birer *haksızlık şekilleri* olarak anlaşılmaktadırlar⁶⁸⁸. Ancak, kusurun, kast ve taksirden

⁶⁸² İÇEL, Kayıhan: *Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk*, İstanbul, 1967, sh. 10 vd.

⁶⁸³ Bu teorik gelişim hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 221 vd.

⁶⁸⁴ WELZEL, Lehrbuch, sh. 139; MAURACH/ZIPF I, sh. 403/404; JESCHECK, Lehrbuch(4) sh. 384, 535; aynı yazar, Ceza Hukuku, sh. 26 vd.; WESSELS(19), sh. 110/111, 113; YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 251/252, 305 vd; aynı yazar: *Ceza Hukukunun Temel Kavramları*, 1985, sh. 53; aynı yazar: *Ümanizma Görüşü ile Hukuki Bilmeme ve Yanılma*, Birinci Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğler, Ankara, 1972'den ayrı bası, sh. 10; SÖZÜER, Adem: *Hukuki Hata*, Yargıtay Dergisi, cilt 21, Ekim 1995, sayı 4, sh. 472. *Toroslu*, “kınama yargısı” veya “kusurluluk yargısı” gibi kavramlardan söz etmektedir (TOROSLU Ceza Hukuku, sh. 99, 100). Ayrıca bkz. ARTUK, Ceza Hukuku El Kitabı, sh. 216. Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 76 vd., 78 vd.; aynı yazar: *Kusur Yargısı ve Yaş Küçüklüğü*, in: Facultatis Decima Anniversaria (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu), İstanbul, 1993, sh. 251 vd.

⁶⁸⁵ WELZEL, Das neue Bild, sh. 40; MAURACH/ZIPF I, sh. 403; DÖNMEZER, Sulhi: *Cezai Mesuliyetin Esası*, 1949, sh. 21.

⁶⁸⁶ MAURACH/ZIPF I, sh. 402, 457 vd; WESSELS(19), sh. 112, 113, 119; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 382; HARDWIG, Grundprobleme, sh. 9, 10; TOROSLU, Ceza Hukuku, sh. 99.

⁶⁸⁷ ÜNVER, Yener: *Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi* (henüz basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 1989, sh. 70.

⁶⁸⁸ Aksi görüş, hâlâ kast ve taksiri birer yalın “kusurluluk şekli” olarak telâkki etmektedir (BAUMANN, Jürgen/WEBER, Ulrich: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 9. Auflage, 1985, sh. 430/431). Türk Hukukunda halen hakim olan telâkki budur: DÖNMEZER/ERMAN II, no. 917; İÇEL, Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh. 16 vd.; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 257; EREM, Faruk: *Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, cilt I, 12. bası, 1984, sh. 504 vd.; ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 204.

tamamen soyutlanarak, yalın bir değer yargısı olarak kabulü de söz konusu değildir.⁶⁸⁹ Çünkü, haksızlık, kusur yargısının dayanağını teşkil etmektedir; kusur yargısı, gerçekleştirilen bu haksızlık zemini üzerine bina edilmektedir. Haksızlık teşkil eden vakıa ile haksızlık yargısı arasında nasıl zorunlu bir ilişki mevcutsa; sorumluluk ve evleviyetle kusur yargısıyla, bu yargının mesnedini teşkil eden haksızlık arasında da zorunlu bir bağlantı vardır. Böylece, haksızlığın bütün unsurları dolaylı bir şekilde kusurun belirlenmesinde de etkili olmaktadır. Kısacası, haksızlık, kusur yargısının mesnedini teşkil etmektedir, zeminini oluşturmaktadır.^{690 691} Bu şekildeki düşünüş, suçun unsurlarının tamamen haksızlık kapsamında mütalâa edildiği ve kavram olarak kusurun içinin boşaltıldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, kast ve taksirin haksızlık kapsamında mütalâa edilmesi, kusur kavramı açısından bir eksiklik teşkil etmemektedir.⁶⁹²

İşlediği haksızlık dolayısıyla kişi hakkında bir muaheze yargısı ifade eden kusurun unsurlarının belirlenmesinde, bu nedenle, işlenen fiilin (haksızlığın) kasten veya taksirle işlenmesini esas alacağız. Bilahare, bu unsurlar üzerinde etkili olan faktörler üzerinde genel mahiyette açıklamalarda bulunacağız.

II. Kasten İşlenen Suçlarda Kusurluluk

Kasten işlenen suçlarda kusurun iki unsuru mevcuttur: 1) *Algılama yeteneği* (*idrak kabiliyeti*), 2) *İrade yeteneği*.⁶⁹³ Aşağıda açıklamaya çalışacağımız bu iki kabiliyet, birbirleriyle yakın bir bağlantı halindedirler. Kusurun belirlenmesinde, daha ziyade kişinin irade kabiliyetinin yokluğu veya zayıfladığı noktai naza-

⁶⁸⁹ Kusur, mutlaka bir haksızlıkla irtibatlandırılmalıdır. Bir başka ifadeyle, ancak bir haksızlığın gerçekleştirilmiş olması dolayısıyla kişi kusurlu addedilebilir. (SCHMIDHAEUSER, Lehrbuch, § 4, kn. 9; BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 23, kn. 5).

⁶⁹⁰ ROXIN, Lehrbuch(1), § 10 kn. 68, 69, § 12 kn. 26 ve özellikle § 19 kn.14-15.

⁶⁹¹ Ancak, Alman Ceza Hukuku doktrinde kasdın hem haksızlık sahasında hem de kusur sahasında bir pozisyona, mevkiye sahip olduğu (Doppelstellung des Vorsatzes), başka bir ifadeyle, hem haksızlık sahasında hem de kusur sahasında fonksiyon icra ettiği (Doppelfunktion des Vorsatzes) fikri oldukça kabul görmüştür: Kavramı ilk kullanan GALLAS, Wilhelm: *Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen*, in: ZStW 67(1955), sh. 44 vd. (ayrıca, GALLAS, Wilhelm: *Beiträge zur Verbrechenslehre*, Berlin, 1968, sh. 56); bilahare JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 218, 387, ayrıca, sözkonusu kitabın 4. basısının Önsözü (Vorwort zur 4. Auflage); WESSELS(19), sh. 42-44, 120; LENCKNER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. §§ 13 ff., kn. 52 vd., 120; ZIEGERT, Ulrich: *Vorsatz, Schuld und Vorverschulden*, 1987, sh. 137 vd.; ROXIN, Kriminalpolitik, sh. 21, 42/43; SCHÜNEMANN, Bernd: *Einführung in das strafrechtliche Systemdenken*, in: Grundfragen des modernen Strafrechtssystems (Hrsg.: Bernd Schünemann), Berlin, 1984, sh. 60/61. Bu fikre eleştiri için bkz. MAURACH/ZIPF I, sh. 292. Aynı şekilde taksirin de hem bir haksızlık şekli, hem de bir kusur şekli olduğu iddia edilmiştir: WESSELS(19), sh. 202; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh.509 ve dn. 9'da belirtilen referanslar.

⁶⁹² JAKOBS, Lehrbuch(1), § 17, kn. 44.

⁶⁹³ İdrak ve irade kabiliyeti kavramları ve izahları açısından bkz. ALACAKAPTAN, sh. 9, 104; YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 306 vd.; DÖNMEZER, Cezaî Mesuliyetin Esası, sh. 20/21; ÇI-NAR, Ön Kusurluluk, sh. 24, 42, 72 vd.

rına dayanılmaktadır. İrade kabiliyetinin yokluğu, bazı hallerde idrak kabiliyetinin yokluğuna ve sair faktörlere bağlı olabilmektedir.⁶⁹⁴

Kişinin idrak ve/veya irade kabiliyetine sahip olup olmadığı, mücerret bir şekilde değil; ancak gerçekleştirdiği muayyen haksızlık açısından tayin edilecektir.⁶⁹⁵ Bir başka ifadeyle; kişinin işlediği fiil dolayısıyla kusur yeteneğinin var olup olmadığı, her müşahhas olayın şartlarını gözönünde bulundurarak tayin etmek mümkündür.⁶⁹⁶ Meselâ bir kleptomani akıl hastasının işlediği muayyen tarzdaki bir hırsızlık suçu açısından irade kabiliyetinin mevcut olmadığını kabul edebilirken; bir kasten yaralama suçu açısından aynı şeyi söylemek mümkün değildir.⁶⁹⁷

A. Algılama Yeteneği

1) Haksızlık Bilinci

İnsan, kendi varlığının bilincinde olarak, çevresindeki vakıaları, olguları gözlemleyebilmekte, bu gözlemlerinden belli sonuçlar çıkarabilmektedir; davranışlarını vardığı bu sonuçlar doğrultusunda yönlendirebilmektedir.⁶⁹⁸ İnsanın çevresindeki olguları gözlemleyebilme yeteneğine *algılama yeteneği* (idrak kabiliyeti)⁶⁹⁹ demektir. Algılama yeteneğinin gelişimi, insanın dimağ gelişiminin yanı sıra, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevrenin şartlarıyla da yakinen bağlantılıdır. İnsanın çevresindeki vakıalara ilişkin gözlemlerinden çıkardığı sonuçların bir hukuki değer ifade edebilmesi için; bunların, bir toplumda genel kabul görmüş olan ve topluma *hukuk toplumu*⁷⁰⁰ niteliğini kazandıran davranış normlarıyla ilişkili olması gerekir. Bir başka ifadeyle; insan bu gözlemlerinden bir sonuç çıkarırken, yükümlülüklerinin ve bunlara aykırı davranması halinde sorumlu tutulacağı bilinciyle hareket etmelidir.⁷⁰¹ Bu bilince rağmen; insanın davranış normlarına aykırılık arzeden ve dolayısıyla, haksızlık teşkil eden bir fiil işlemesi; muaheze edilmesinin sebebini oluşturmaktadır. Yani, kişi; işlediği fiilin davranış normlarına aykırı olduğunu ve dolayısıyla, haksızlık teşkil ettiğini bilmesine rağmen; tercihini bu fiili işlemekten yana kullanmıştır, bu fiili işlemekten vazgeçmemiştir. Bu itibarla, işlediği fiilden dolayı kusurlu addedilebilmesi için; kişinin bu fiilin bir haksızlık teşkil ettiğini, davranışının hukuk top-

⁶⁹⁴ ROXIN, Lehrbuch, § 20, kn. 28.

⁶⁹⁵ ROXIN, Lehrbuch, § 20, kn. 30; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 392; MAURACH/ZIPF I, kn. 483; LENCKNER, Schönke/Schröder(23), § 20, kn. 25 vd. (31).

⁶⁹⁶ YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 308.

⁶⁹⁷ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 80 vd.; aynı yazar, *Facultatis Decima Anniversaria*, sh. 253.

⁶⁹⁸ DREHER, Eduard: *Die Willensfreiheit*, 1987, sh. 380; KAUFMANN, Arthur: *Das Schuldprinzip*, 1961, sh. 116 vd; aynı yazar: *Recht und Sittlichkeit*, 1964, sh. 11/12.

⁶⁹⁹ Einsichtsfähigkeit.

⁷⁰⁰ Rechtsgemeinschaft.

⁷⁰¹ Pflicht - und Verantwortungsbewusstsein.

lumunda hakim olan düzeni korumaya matuf bir davranış normunu ihlâl ettiğini bilmesi gerekir⁷⁰². Diğer bir deyişle; kişi, işlediği fiilin hukuken tasvip edilmez bir fiil olduğunun bilincinde olmalıdır⁷⁰³. Ancak, işlenen fiilin pozitif hukuk metinlerinde cezalandırılabilir bir fiil olarak, yani suç olarak tanımlanmış olduğunu bilmek gerekmez⁷⁰⁴. Hatta, işlenen fiilin bir haksızlık teşkil ettiğinin bilincinde olduktan sonra; ayrıca cezaya layık bir haksızlık⁷⁰⁵ olduğunun bilinip bilinmediğinin araştırılmasına gerek yoktur⁷⁰⁶.

2) Teorik Gelişim

19. yüzyılda ceza hukukuna hakim olan anlayışa (klasik suç teorisine) göre; suçun unsurlarındaki yanlışlığa “maddi hata”⁷⁰⁷; buna karşılık, işlenen fiilin hukuk kurallarına aykırılık teşkil ettiği hususundaki yanlışlığa “hukuki hata”⁷⁰⁸ denilmektedir. “Hukuki hata” da, ceza hukukuna ilişkin olan ve olmayan hukuki hata olarak, ikiye ayrılmaktaydı. Ceza hukuku sahası dışındaki hukuki hata; ceza hukuku dışındaki hukuki ilişkilere, hukuki statülere ilişkin yanlışlığı ifade etmekteydi. Bu yanlışlık, “maddi hata” ile aynı muameleye tabi tutulmaktaydı. Buna karşılık; ceza hukuku sahasına giren hukuki hata ise, ceza kanununun ifade ettiği yasaklar konusundaki veya esasen mevcut olmayan bir hukuka uygunluk sebebinin varlığını kabul gibi yanlışlıkları içermektedir. Bu yanlışlık şekli, “*error iuris nocet*” (“*kanunu bilmemek mazeret sayılmaz*”) kuralı kapsamında mütalâa edilmekteydi⁷⁰⁹. “Error iuris nocet” kuralına ilişkin bir görüşe göre, işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiğinin bilinmesi, cezalandırmanın bir şartını teşkil etmez. Diğer bir anlayışa göre, işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiğinin bilinmesi, kişiyi cezalandırmak için gereklidir; ancak, toplumda yaşayan herkesin, genel olarak,

⁷⁰² BGH, Grosser Senat für Strafsachen, 17.2.1954 (BGHSt 6[1954], sh. 46 vd. [52 vd., 59]); BGH, Grosser Senat für Strafsachen, 10.3.1954 (BGHSt 6[1954], sh. 147 vd. [153]).

⁷⁰³ JAKOBS, Lehrbuch(1), § 19, kn. 23 vd.; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 408 vd.; aynı yazar, Ceza Hukuku, sh. 29/30; MAURACH/ZIPF I, sh. 524 vd.; BLEI, Allgemeiner Teil, sh. 198 vd.; KAUFMANN, Arthur: *Das Unrechtsbewußtsein in der Schuldlehre des Strafrechts*, 1950, sh. 142 vd; aynı yazar, *Das Schuldprinzip*, sh. 130 vd.; BEHRENDT, sh. 49.

⁷⁰⁴ Ünver, yeni TCK’nın 4. maddesi ile 30. maddesinin dördüncü fıkrasının tarafımızdan kaleme alınan gerekçelerinde yer alan fiilin suç oluşturduğu hususuna ilişkin bilmemenin önemsiz olduğu yönündeki açıklamayı doğru bulmamaktadır (ÜNVER, Yener: YTCK’da Kusurluluk, in: Ceza Hukuku Dergisi, yıl 1, sayı 1, Ekim 2006, sh. 38). Ancak, söz konusu tebliğ metninde bunun gerekçesi açıklanmış değildir.

⁷⁰⁵ Strafwürdiges Unrecht.

⁷⁰⁶ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 214 vd.; MAURACH/ZIPF I, sh. 524/525; WESSELS(19), sh. 120; SÖZÜER, YD 21(1995), sh. 479 vd. Ayrıntılı bilgi için bkz. GÖKTÜRK, Haksızlık Yanılgısının Ceza Sorumluluğuna Etkisi, sh. 46 vd.

⁷⁰⁷ Tatsachenirrtum.

⁷⁰⁸ Rechtsirrtum.

⁷⁰⁹ Bu gelişim hakkında bilgi için bkz. v.LISZT/SCHMIDT, Lehrbuch(24), sh. 180 vd.; ayrıca, Grosser Senat für Strafsachen, 18.3.1952 (BGHSt 2[1952], sh. 194 vd.).

hukuk kurallarının bilincinde olduğu farzedilir. Algılama yeteneğine sahip herkesin ceza kanunlarını bildiği farzedilmiştir⁷¹⁰.

Doktrinde zamanla oluşan bir görüşe göre; pozitif hukuk düzenlemelerinin karmaşık bir yapı alması dolayısıyla, bazen kişi işlediği fiilin hukuka aykırılık teşkil ettiğini bilemeyebilir. Bunun sonucu olarak; “*dolus malus*” fikri gelişmeye başlamıştır⁷¹¹. Bu anlayış, nihayet doktrinde “*kast teorisi*” olarak formüle edilmiştir: Kişi işlediği fiilin haksızlık teşkil ettiğini biliyorsa, kasten hareket etmiş demektir. Kasdî suçtan sorumluluk için, işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiğinin şuurunda olmak gerekir. İşlediği fiilin bir haksızlık teşkil ettiğini bilmemekle beraber; somut olayda kişi bu fiilin bir haksızlık teşkil ettiğini bilebilecek durumda ise, taksirle hareket etmiş demektir. Şayet bu fiilin taksirle işlenmiş olması kanunda suç olarak tanımlanmış ise, kişi ancak taksiri dolayısıyla cezalandırılacaktır⁷¹².

Amaççı (gaî, final) suç teorisinin etkisiyle, normatif kusur kavramı yeni bir veçhe kazanmıştır. Bu anlayışa göre, kast, suçun salt manevi unsuru olarak, haksızlık kapsamı içinde mütalâa edilmelidir⁷¹³. Haksızlık, yasaklanmış bulunan bir hareketin bütün manevi unsurlarını bünyesinde bulundurmaktadır. Buna karşılık, kusur, söz konusu haksızlığı gerçekleştiren kişinin bu fiil dolayısıyla kınanabilirliğini ifade etmektedir. İşlediği fiilin haksızlık teşkil ettiği hususundaki bilinç, kusur kapsamı içinde düşünülerek, kasttan ayrık tutulmuştur. Yani, kast, sadece işlenen haksızlığın maddi şartları konusundaki bilinci kapsamaktadır. Buna karşılık, işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususundaki bilinç ise, kusurun bir unsurunu oluşturmaktadır: *kusur teorisi*⁷¹⁴.

⁷¹⁰ Bu konuda bilgi için bkz. JAKOBS, Günther: *Das Schuldprinzip*, 1993, sh. 16.

⁷¹¹ v.HIPPEL, Lehrbuch, sh. 139 vd.

⁷¹² MEZGER, *Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik*, sh. 43; aynı yazar, *Studienbuch*(9), sh. 180 vd.; SCHMIDHAEUSER, Lehrbuch, § 4, kn. 10, 25, 26, § 7, kn. 12, 36, 42, 87, § 8, kn. 4 vd.; HARDWIG, *Grundprobleme*, sh. 38; LANGER, Winrich: *Das Sonderverbrechen, Eine dogmatische Untersuchung zum Allgemeinen Teil des Strafrechts*, 1972, sh. 293 vd., 356 vd.; BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 20, kn. 31, 40; MAYER, Hellmuth: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 1953, sh. 249; Türk Hukukunda ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 309, 310, 365; YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 329; aynı yazar, *Hukuki Bilmeme ve Yanılma*, sh. 18. Bu hususta bilgi için bkz. SÖZÜER, YD21(1995), sh. 474 vd.

⁷¹³ WELZEL, *Das neue Bild*, sh. 41 vd.; aynı yazar, Lehrbuch(11), sh. 140 vd; STRATENWERTH, *Allgemeiner Teil*, kn. 509; MAURACH/ZIPF I, sh. 410; ayrıca bkz. ACHENBACH, Hans: *Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematisch-hen Schuldlehre*, 1974, sh. 209 vd.

⁷¹⁴ WELZEL, ZStW 58[1939], sh. 546; aynı yazar, Lehrbuch(11), sh. 164 vd.; NIESE, Finalitaet, sh. 33 vd.; MAURACH, Lehrbuch(4), sh. 468 vd.; GALLAS, Beitrage, sh. 56, dn. 89. Bilgi için bkz. SÖZÜER, YD21(1995), sh. 477 vd. Türk hukukunda Kunter, “tipikliği bilmemenin kasdın bir unsuru olarak telâkisi”ne karşı çıkmaktadır (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 72). Fakat, bu bilmenin hangi kapsamda tetkik edilmesi gerektiği hususunda herhangi bir açıklamaya yer vermemektedir.

İşlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususunda düşülen yanlış kaçınılmaz ise, kişi kusursuz addedilecektir. Buna karşılık, söz konusu yanlış, kişi açısından kaçınılabilir⁷¹⁵ ise, yanlışın varlığına rağmen, kişi kusurlu telâkki edilecektir. Bir başka ifadeyle; içinde bulunduğu şartlar itibarıyla gerekli özeni göstermiş olsaydı, işlediği fiilin haksızlık teşkil ettiğini bilebilecek idiyse, kişi kusurludur. Ancak, bu durumda kasten işlediği suç dolayısıyla kişiye verilecek cezada bir indirim yapılabilecektir⁷¹⁶.

Amaççı suç teorisinin kurucusu olan Alman hukukçusu *Welzel*, bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları konusundaki yanlışlığı da haksızlık yanlışlığı içinde mütalâa ettiği için, “*katı kusur teorisi*”ne⁷¹⁷ taraftardı. Hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarındaki yanlış konusunda, ister *Welzel*’in çözümünü benimsemiş olsun, ister farklı çözüm yollarını savunmuş olsunlar; işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususundaki yanlışın (haksızlık yanlışlığı) kusur sahasında mütalâa edilmesi gerektiği konusundaki fikir, bugün Alman ceza hukuku doktrininde hakim durumdadır⁷¹⁸.

B. İrade Yeteneği

1) *Muaheze Yargısı ve İrade*

Yukarıda da izah ettiğimiz gibi; fiil, yönlendirici irade tarafından hakim olunan, belli bir neticenin gerçekleşmesi gayesine matuf, gaî, ereksel (fînal) ve haricî dünyada cereyan eden bir insan hareketidir⁷¹⁹. Buna göre, insan davranışlarının yönlendirici iradenin ürünü olması, fiil kavramının bir vasfını teşkil etmektedir⁷²⁰. Doktrinde fiil kavramına yüklenen en önemli fonksiyon, fiil vasfını taşımayan insan davranışlarının hukuk sahasından öncelikle ayıklanmasını sağlamaktır. Demek ki, irade ürünü olmayan insan davranışlarının fiil vasfını haiz olmadıklarını evleviyetle söyleyebiliriz⁷²¹.

⁷¹⁵ Kaçınılabilirlik konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. GÖKTÜRK, Haksızlık Yanılgısının Ceza Sorumluluğuna Etkisi, sh. 141 vd.

⁷¹⁶ Grosser Senat für Strafsachen, 18.3.1952 (BGHSt 2[1952], sh. 209 vd.

⁷¹⁷ “strenge Schuldtheorie”.

⁷¹⁸ GALLAS, Beiträge, sh. 56, dn. 89; ROXIN, Claus: *Offene Tatbestände und Rechtspflichtmerkmale*, 2. Auflage, 1970, sh. 112 vd., 120; aynı yazar, *Täterschaft und Tatherrschaft*, 4. Auflage, 1984, sh. 198/ 199; aynı yazar, *Lehrbuch*(1), § 12, kn. 82; MAURACH/ZIPF I, sh. 292, 293/294, 501/502, 511, 513, 521/522, 534; BLEI, Allgemeiner Teil[17], sh. 117/118, 178/179; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 581, 612; JESCHECK, *Lehrbuch*(4), sh. 406 vd.; WESSELS(19), sh. 120, 135 vd.; ayrıca BOCKELMANN, Paul: *Über das Verhältnis von Täterschaft und Teilnahme*, 1949, sh. 39, 51.

⁷¹⁹ MAURACH/ZIPF I, sh. 175, 185.

⁷²⁰ İrade kavramı hakkında geniş bilgi için bkz. EREM, Faruk: *Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi*, 10. bası, 1997, sh. 32 vd.

⁷²¹ ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 92 vd.; aynı yazar, *Facultatis Decima Anniversaria*, sh. 255 vd.

Ancak, fiilin vasfı olarak kabul ettiğimiz iradenin ne tür bir irade olduğunu da belirlemek gerekir. Fiilin varlığından bahsedebilmek için aranan irade, değerden yoksun bir iradedir⁷²². Bu irade, belli bir davranışa ilişkin plan, bu davranışa ilişkin önceden tasarlanan illi oluşum serisi hakkındaki bilgiye dayanmaktadır. Bir başka ifadeyle, bu bilgi ve dolayısıyla irade, sadece suçun maddi unsurlarına ilişkindir⁷²³. Bu husus, iradenin oluşum sürecindeki ilk aşamayı teşkil etmektedir⁷²⁴. İkinci aşamada ise; kişi, davranış normlarına rağmen, planladığı bu davranışının bir değerlendirmesi cihetine gider. Davranış normlarının anlam muhtevasının şuurunda olmasına rağmen, kişi yine de bu normlara aykırı davranma doğrultusunda tercihini kullanmaktaysa; işte bu noktada iradenin bir değer ifade ettiğinden ve dolayısıyla, kusurun bir unsurunu oluşturduğundan bahsedebiliriz⁷²⁵.

Buradan çıkaracağımız diğer sonuç da; kusurun unsurunu oluşturan iradenin, davranış normlarının anlam muhtevasının bilinmesini, bunların şuurunda olmayı gerekli kılmasıdır. Bir başka ifadeyle, anlam muhtevası idrak edilememiş bir norma aykırı davranışa ilişkin değer ifade eden bir iradeden bahsedilemez⁷²⁶. Ayrıca, yukarıda da belirttiğimiz gibi, suçun maddi unsurlarına ilişkin bilgiyi ifade eden kast, normun anlam muhtevasına ilişkin bilgiyi ifade etmemektedir⁷²⁷.

Bu izahlar sayesinde fiil ehliyetiyle kusur ehliyetini birbirinden ayırmamız mümkün olacaktır. Kusur ehliyetinin ve dolayısıyla, kusurun mevcut olup olmadığının araştırılması için, önce ortada bir fiilin varlığının ve evleviyetle, kişinin fiil ehliyetine sahip olduğunun sabit olması lazımdır⁷²⁸.

2) İrade Hürriyeti

Burada klasik ceza hukukçularının savunduğu irade hürriyetinin mevcudiyetini esas alan *indeterminist* ve pozitivist ceza hukukçularının savunduğu iradenin hür olmadığı doğrultusundaki *determinist* görüşlerin tartışmasına girmeksizin⁷²⁹; biz, işlediği fiilin hukuki anlam muhtevasını idrak eden kişinin kendisine etkide bulunan sevki tabîleri, iç dürtüleri kontrol altına alarak, toplumda mevcut ve hakim değerler ve dolayısıyla, davranış normlarının kendisine yüklediği yüküm-

⁷²² MAURACH/ZIPF I, sh. 188.

⁷²³ MAURACH/ZIPF I, sh. 472.

⁷²⁴ Kararın oluşum süreci hakkında bilgi için bkz. EREM, Adalet Psikolojisi, sh. 35.

⁷²⁵ Her ne kadar iradenin oluşum süreci dediğimiz bu zihni faaliyeti genellikle zaman itibarıyla bir aşamalandırmaya tabi tutmak mümkün olmasa da ve bu aşamalar iç içe bir mahiyet arz etmekteyse de, suç teorisine ilişkin mülahazalarla meselenin bu şekilde izahı kaçınılmazdır.

⁷²⁶ Bilinç ve irade ilişkisi açısından bkz. EREM, Adalet Psikolojisi, sh. 36 vd.

⁷²⁷ MAURACH/ZIPF I, sh. 472.

⁷²⁸ ROXIN, Lehrbuch(1), 20/29.

⁷²⁹ Determinist ve indeterminist görüşler hakkında bilgi için bkz. DÖNMEZER, Cezaî Mesuliyetin Esası, sh. 144 vd., 152 vd.

lülükler doğrultusunda karar verme yeteneğine sahip olmasını irade hürriyeti olarak telâkki etmekteyiz⁷³⁰.

Kişinin kusurundan bahsedebilmek için; fiili işlediği sırada davranış normunun gerektirdiği şekilde karar verebilecek iktidara, kabiliyete sahip olması gerekir. Kişi, ruhen sağlıklı yetişkin her insanın normal şartlar altında sahip olduğu davranışlarını yönlendirebilme kabiliyetine işlediği fiil açısından, müşahhas olayda sahip olmalıdır ki; gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla kusurundan bahsedilebilsin⁷³¹.

Ruhen sağlıklı yetişkin her insan, normal şartlar altında bu kabiliyeti haizdir. Bu durumda olan bir kişinin “gerçekten” irade kabiliyetine sahip olup olmadığını ayrıca araştırmamıza gerek yoktur. Bu itibarla, irade hürriyeti açısından kusurluluğun tespiti *normatif* bir mahiyet arzedecektir⁷³². Kusurun tespitinde kişinin irade hürriyetine sahip olduğu, tabir yerindeyse, bir “postulat” olarak telâkki edilecektir⁷³³. Hürriyet esasına dayalı bir toplumda, yetişkin ve ruhî bakımdan vasat bir sağlığa sahip insanların sorumluluk şuuruyla ve irade serbestisiyle hareket ettiklerini kabul etmek, kaçınılmaz bir gerçektir⁷³⁴. Şayet kişinin fiili işlediği sırada gerçekten irade serbestisine sahip olup olmadığının araştırılması cihetine gidilecekse, bundan sağlıklı bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Bilişimin bugünkü verileri dikkate alındığında; bir insanın belli şartlar içinde davranışlarını yönlendirebilme (irade) kabiliyetine, bilimsel olarak, “gerçekten” sahip olup olmadığını tespit etmek mümkün değildir.

Demek ki, kusurun tespitinde iki vakıadan hareket edeceğiz:

1) Ruhen sağlıklı yetişkin her insanın normal şartlar altında hukuk düzeninin idamesi için zarurî olan irade gücüne sahip olduğu farzedilecektir. Yetişkin ve ruhî, aklı bakımdan vasat sağlığa sahip bir insanın normal şartlar altında işlediği haksızlıktan dolayı sorumlu tutulması -kusurlu sorumluluk-, sosyal ve ahlâkî şuorumuzun zarurî bir sonucudur. Bedenî bakımdan yetişkin, ruhî bakımdan vasat bir sağlığa sahip, akletme kabiliyeti olan, işlediği fiilin ilişkin olduğu davranış normunun anlam muhtevasını idrak eden ve bu şuur doğrultusunda davran-

⁷³⁰ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 369; WESSELS(19), sh. 111; LENCKNER, Schönke/ Schröder(23), Vorbem. §§13 ff., kn. 110, 118; BLEI, Allgemeiner Teil(18), sh. 177; RUDOLPHI, Systematischer Kommentar, §20, kn. 25; BLEI, Allgemeiner Teil(3), sh. 110; STRATENWERTH, *Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips*, Heidelberg/Karlsruhe, 1977, sh. 17; SCHÜNEMANN, Bernd: *Die Funktion des Schuldprinzips im Präventionsstrafrecht*, in: Grundfragen des modernen Strafrechtssystems (Hrsg.: Bernd Schünemann), 1984, sh. 163 vd.; aynı yazar: *Strafrechtssystem und Kriminalpolitik*, in: Festschrift für Rudolf Schmitt, 1992, sh. 134.

⁷³¹ ROXIN, Lehrbuch(1), 19/34.

⁷³² ROXIN, Lehrbuch(1), 19/35; LENCKNER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. §§ 13 ff., kn. 110.

⁷³³ LENCKNER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. §§ 13 ff., kn. 110.

⁷³⁴ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 369/370.

nışlarını yönlendirebilme (irade) kabiliyeti mevcut olan bir kişiyi, bütün bu yeteneklerine rağmen bir haksızlık gerçekleştirmesinden dolayı kusurlu telâkki etmekteyiz, bu kişi açısından muaheze yargısında bulunmaktayız.

2) Failin kişiliğinde veya fiilin işlenişi esnasında mevcut olan, ancak, mutad olmayan, istisnaî bazı haller dolayısıyla yetişkin insanlardaki davranış normlarının anlam muhtevasını idrak kabiliyetinin ve bu şuur doğrultusunda davranışlarını yönlendirebilme (irade) kabiliyetinin ortadan kalktığını söyleyebiliriz⁷³⁵. Bu yönü itibarıyla, kusurun normatif, yani değerlendirmeye dayanan ve aynı zamanda tecrübî (ampirik) bir vakıa olduğundan bahsedilmektedir⁷³⁶. Demek ki kusur, münhasıran normatif bir mahiyet arzermeyip; aynı zamanda tecrübî (ampirik), biyolojik ve psikolojik bir temele dayanmaktadır⁷³⁷.

3) İrade Yeteneğinin Derecelendirilmeye Tabi Tutulması

Algılama yeteneğinin aksine, irade yeteneği bir derecelendirmeye tabi tutulabilecek mahiyettedir⁷³⁸. Bu itibarla, irade kabiliyetinin mevcudiyetine rağmen, önemli ölçüde azalmış olması halinde; kişinin kusurunda bir azalmanın varlığından bahsetmek gerekir⁷³⁹. İrade kabiliyetinin zayıflamış olması durumunda, kusurun varlığı kabul edilmekle beraber; bu husus, cezanın veya genel olarak müeyyidenin tayininde fail lehine gözönünde bulundurulması gereken önemli bir faktördür. Nitekim, TCK, haksız tahrik halinde, haksız bir fiilin meydana getirdiği gazabın etkisi altındaki kişinin irade kabiliyetinin önemli ölçüde zayıfladığı düşüncesiyle⁷⁴⁰, failin cezasında zorunlu olarak indirim yapılması gerektiğini kabul etmektedir (m. 29; 765 s. TCK, m. 51, 462)^{741, 742}.

⁷³⁵ *Toroslu*, yeni TCK'nın 32. maddesinde yapılan düzenlemeyi eleştirirken algılama yeteneğinin de derecelendirmeye tabi tutulabileceği şeklinde yanlış bir kabulden yola çıkmıştır (TOROSLU, Nevzat: *Ceza Hukuku, Genel Kısım*, 8. bası, Ankara, Ekim 2005, sh. 341).

⁷³⁶ ROXIN, Lehrbuch(1), 19/39, 20/2.

⁷³⁷ ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 95; aynı yazar, *Facultatis Decima Anniversaria*, sh. 256 vd.

⁷³⁸ ROXIN, Lehrbuch(1), 20/32; MAURACH/ZIPF I, sh. 490, 492; BAYRAKTAR, Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, sh. 20. Hiddet, gazap ve şiddetli elem kavramları hakkında bilgi için bkz. EREM, Adalet Psikolojisi, sh. 84 vd.

⁷³⁹ ROXIN, Lehrbuch(1), 20/32; MAURACH/ZIPF I, sh. 490, 492; BAYRAKTAR, Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, sh. 20. Hiddet, gazap ve şiddetli elem kavramları hakkında bilgi için bkz. EREM, Adalet Psikolojisi, sh. 84 vd.

⁷⁴⁰ ÖNDER, Genel Hükümler II, 375/376; DEMİRBAŞ, Timur: *Türk Ceza Kanununda Özel Haksız Tahrik Halleri*, 1985, sh. 37. Haksız tahrik dolayısıyla aynı zamanda işlenen fiilin haksızlık muhtevasının da azaldığı görüşüne (KERN, Eduard: *Grade der Rechtswidrigkeit*, ZStW 64[1952], sh. 286) iştirak etmemekteyiz.

⁷⁴¹ CGK., 31.10.1994, 1-225/250 (YKD, Şubat 1995, sh. 299 vd. [302]); CGK., 21.6.1993, 4-154/183 (YKD, Aralık 1993, sh. 1867 vd. [1869/1870]).

⁷⁴² Tahrik olgusuyla bağlantılı olarak yığın içindeki kişinin irade kabiliyeti hakkında bilgi için bkz. BAYRAKTAR, Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, sh. 147 vd., özellikle sh. 163/164; EREM, Adalet Psikolojisi, sh. 196 vd.

III. Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluk

Taksirli davranışla gerçekleştirilen haksızlıklarda fail, kendi şahsi kabiliyetleri, idrak gücü, tecrübeleri, bilgi düzeyi ve içinde bulunduğu şartlar itibarıyla, objektif olarak mevcut bulunan özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmalıdır. Bütün bu kabiliyetlere şahsen sahip olan kişi, buna rağmen bu yükümlülüğe aykırı davranması sonucunda bir hukuki değeri zarara uğratması ve ya müşahhas bir tehlikeye maruz bırakması durumunda, taksirli haksızlıktan dolayı kusurlu telâkki edilecektir⁷⁴³. Buna göre, kişi, objektif özen yükümlülüğünün mevcudiyetini ve muhtevasını idrak edebilecek ve aynı zamanda bu doğrultuda hareket edebilecek durumda olmalıdır⁷⁴⁴. Objektif özen yükümlülüğünün kişi tarafından idrak edilebilir olması, aynı zamanda bu yükümlülüğe aykırılık dolayısıyla meydana gelen neticenin öngörülebilir olmasını da ifade etmektedir⁷⁴⁵.

Taksirle işlenen suçun haksızlık unsurunun gerçekleşmesi, kasten işlenen suçlarda olduğu gibi, kusurun emaresini teşkil etmektedir. Buna göre, kişinin akletme kabiliyeti bakımından, ruhî bakımdan bir malûliyetinin söz konusu olduğu, objektif özen yükümlülüğünün şuurunda olmadığı veya içinde bulunduğu şartlar itibarıyla irade kabiliyetinin mevcut olmadığı hususlarında şayet müşahhas dayanak noktaları mevcutsa, taksirle işlenen suçtan dolayı failin kusursuz olduğu yargısına varabiliriz⁷⁴⁶.

A. Algılama Yeteneği

Kasten işlenen suçlarda olduğu gibi, taksirle işlenen suçlarda da kişi, objektif özen yükümlülüğünün varlığının ve bunun muhtevasının idrakinde (haksızlık şuuru) veya bunu idrak edebilecek durumda (potansiyel, bilkuvve haksızlık şuuru) olması lazımdır. Şayet böyle bir özen yükümlülüğünün varlığı veya muhtevası konusunda yanlışlığa düşülmüşse, bir haksızlık yanlışlığı mevcuttur. Meselâ meskûn bir mahalde belirlenmiş azamî hız sınırının üzerinde vasıta kullanılmayacağı şeklindeki Hukuk kuralının bizzat varlığında veya muhtevasında⁷⁴⁷ yanlışlığa düşen kişi, bu hız sınırının üzerinde vasıta kullanmak suretiyle bir başkasının ölmesi veya yaralanmasına sebebiyet vermesi halinde, söz konusu objektif özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışta bulunmuştur. Yani, taksirli suçun haksızlık unsuru gerçekleşmiştir. Ancak, kişi azamî hız sınırının varlığı-

⁷⁴³ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 510, 536 vd.; WESSELS(19), sh. 203, 208, 216; ROXIN, Lehrbuch(1), 24/102 vd. Ancak, doktrinde bir görüş, objektif özen yükümlülüğünün müşahade edilebilir olmasını “taksirli suç”un, taksirli haksızlığın manevî unsuru olarak telâkki etmektedir: MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 112, 138 vd.

⁷⁴⁴ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 536 vd.

⁷⁴⁵ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 539.

⁷⁴⁶ ROXIN, Lehrbuch(1), 24/113.

⁷⁴⁷ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, m. 50 vd.

nın veya muhtevasının bilincinde olmadığı için, burada bir haksızlık yanılığı söz konusudur. Bu yanılığın kaçınılmaz olması halinde, kusursuz olduğu için, kişi cezalandırılmaz. Şayet kişinin bu yanılığı kaçınılabılır bir yanılığa ise, kusurunun azaldığı dikkate alınarak, yine taksirli suç esas alınmak suretiyle, cezalandırılması cihetine gidilir⁷⁴⁸.

B. İrade Yeteneği

Failin, objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmasının mümkün olmadığı, kendisinden beklenemediği durumlarda, cezalandırılması cihetine gidilemez. Ancak, bu durumda, taksirle işlenen suçun haksızlık teşkil etme özelliği devam eder; sadece failin kusurunun olmayışından bahsedebiliriz⁷⁴⁹. Kişi, bilincinde olarak, belli bir hukuki değeri korumaya matuf objektif özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışta bulunmaktadır, bir fiil işlemektedir. Ancak, irade kabiliyetinin bertaraf edildiği veya zayıfladığı durumlarda, bu bilince rağmen, taksirle işlenen suçtan dolayı kişinin kusursuz veya kusurunun azalmış olduğunu kabul etmek gerekecektir. Meselâ işledikleri suçtan sonra olay yerinden uzaklaşmak için bir taksiye binen kişiler, taksi şoförüne cebir ve/veya tehdit kullanarak, onu aşırı hızla vasıta sürmeye sevkederler. Bu suretle objektif özen yükümlülüğüne aykırı vasıta kullanan şoför, sonuçta bir kişiye çarparak ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet verir. Bu örnek olayda taksi şoförü hızlı vasıta sürmek suretiyle objektif özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinin şuurundadır; dolayısıyla, bu fiil neticesinde bir başkasının ölebileceği veya yaralanabileceği öngörülebilir durumdadır. Her ne kadar kişi objektif özen yükümlülüğünü ihlâl ettiğinin şuurunda ise de; kendisine tatbik edilen cebir ve/veya tehdit neticesinde bu bilinç doğrultusunda, yani objektif özen yükümlülüğüne uygun olarak davranışlarının yönlendirebilme (irade) kabiliyetini kaybetmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, taksirli suçun haksızlık unsuru gerçekleşmiş olmasına rağmen, kişiyi bu haksızlıktan dolayı muaheze edemeyeceğiz.

IV. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler

Kusurluluğu etkileyen nedenler, şu şekilde bir sıralamaya tabi tutulabilir:

- 1) Yaş küçüklüğü (m. 31),
- 2) Akıl hastalığı (m. 32),
- 3) Sağır ve dilsizlik (m. 33),
- 4) Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma (m. 34),
- 5) Cebir veya tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi (m. 28),

⁷⁴⁸ Arm. KAUFMANN, Normentheorie, sh. 323, 325; ROXIN, Lehrbuch(1), 24/106.

⁷⁴⁹ ROXIN, Lehrbuch(1), 24/107.

- 6) Zorunluluk hali dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi (m. 25, f. 2; m. 92; m. 99, f. 2; m. 143),
- 7) Hukuka aykırı ve fakat, bağlayıcı emrin yerine getirilmesi (m. 24, f. 2 – 4),
- 8) Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması (m. 27),
- 9) Haksız tahrik (m. 29),
- 10) Çeşitli hata halleri (m. 30, f. 3, 4).

A. Yaş Küçüklüğü

Kusur yeteneği üzerinde etkili olan nedenlerin başında **yaş küçüklüğü** gelmektedir. Ancak, buradan kişinin bedenî, fizikî gelişiminin doğrudan kusurluluk üzerinde etkili olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. İnsanın bedenî, fizikî gelişimine paralel olarak; toplumda hakim olan değer telâkkilerini, bu telâkkilerin bağlantılı olduğu, kaynaklandığı davranış normlarının anlam muhtevasını idrak kabiliyeti, kişinin akletme kabiliyeti gelişmektedir. Bu olgunluğa paralel olarak, idrak kabiliyetinin yanı sıra, ayrıca kişinin davranış normlarının icapları doğrultusunda hareketlerini yönlendirebilme (irade) yeteneği de gelişmektedir⁷⁵⁰.

Yeni TCK'nın 31'inci maddesinde, çeşitli yaş kategorileri belirlenmek suretiyle **çocukların**⁷⁵¹ kusur yeteneği ve yaş küçüklüğünün sorumluluk üzerindeki etkisi bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu düzenlemede üç grup yaş kategorisi oluşturulmuştur.

⁷⁵⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “Kusur Yargısı ve Yaş Küçüklüğü”, in: Facultatis Decima Anniversaria (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10 Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu), İstanbul, 1993, sh. 251 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: *Suçun Yapısında Kusur*, (yayınlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul 1997; ÖZGENÇ/ŞAHİN: *Uygulamalı Ceza Hukuku*, 3. bası, Ankara 2001, sh. 243 vd.

⁷⁵¹ Kanunun 6'ncı maddesine göre;

“(1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;

...

b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,

...

Anlaşılır.”

Keza, 3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre (m. 3);

“Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,

...

2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,

...

İfade eder.”

1) Birinci Grup Yaş Küçükleri

Kanun, fiili işlediği sırada henüz oniki yaşını doldurmamış olan çocukların cezai sorumluluk bakımından kusur yeteneğine mutlak bir şekilde sahip olmadıklarını kabul etmektedir (m. 31, f. 1)⁷⁵². Bu grup yaş küçüklerinin cezai sorumluluk bakımından kusur yeteneğinin olmadığı mutlak bir şekilde kabul edilmektedir⁷⁵³. Dolayısıyla, fiili işlediği sırada henüz oniki yaşını tamamlamamış bir çocuğun, kusur yeteneğinin var olup olmadığını araştırmaya gerek yoktur⁷⁵⁴. Ancak, bu demek değildir ki; henüz oniki yaşını tamamlamamış olan çocuk, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme ve davranışlarını hukukun gerekleri doğrultusunda yönlendirebilme yeteneğinden mutlak bir şekilde yoksundur. Aksine, meselâ 10 yaşındaki bir çocuk, taş atarak komşu evin camını kırması veya bir başkasının malını çalması halinde, davranışının yanlışlığının bilincindedir ve kural olarak, kendini de bu fiilleri işlemekten alıkoyabilecek yeteneğe sahiptir. Çoğu zaman çocuklar dahi bir davranışta bulunurken, kendilerini davranış normlarının icaplarına göre motive edebilmektedirler. Ancak, izlenen ceza siyaseti mülahazalarıyla, tekrar suç işlemelerini önleme ve tekrar topluma kazandırılmaları amacıyla, Kanun koyucu bu gruba giren yaş küçüklerinin mutlak bir şekilde cezalandırılmamaları gerektiğini kabul etmiştir. Zira, bu yaş grubundaki çocuklar hakkında ceza yaptırımının tatbiki, cezanın özel önleme ve resosyalizasyon fonksiyonu itibarıyla tamamen ters etki gösterecek mahiyet arz etmektedir. Bu mülahazalarla, bu yaş grubundaki çocukların işledikleri suçlardan dolayı *cezaî* sorumluluklarının olmadığına normatif olarak kabulü isabetli olmuştur⁷⁵⁵.

Ancak, işledikleri suç teşkil eden haksızlıklardan dolayı ve özellikle tehlikelilik durumları dikkate alınarak, bu yaş grubundaki çocuklar hakkında *çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin* uygulanması cihetine gidilebilecektir. Dikkat edilmelidir ki, bu yaş grubundaki çocuklar hakkında kovuşturma yapılamayacaksa da, soruşturma işlemleri yapılabilecektir. Bu çocuklar hakkında, içinde bulundukları aile şartları göz önünde bulundurularak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilecektir⁷⁵⁶. Bu yaş grubuna giren çocuklar hakkında güvenlik

⁷⁵² İşaret edelim ki; gerek 765 s. TCK'nın 53. maddesinde gerek, bu madde hükmünü zımnen ilga eden 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 11. maddesinin birinci fıkrasında mutlak sorumsuzluk yaşının sınırı **onbir yaşın ikmali** olarak belirlenmişti.

⁷⁵³ JESCHECK, Lb., 391; LENCKNER, Schönte/Schröder(23), § 19, kn.3.

⁷⁵⁴ Aksi doğrultuda 3. CD. 27.1.1989, 6470/392: "Suç tarihinde onbir yaşını doldurmamış olan küçük sanığın, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 20. maddesi uyarınca, üzerlerine yükletilen suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden bedeni, aklı ve ruhî durumunun ... araştırılıp belirlenmesi" gerekir (YKD Mayıs 1989, sh. 733).

⁷⁵⁵ ROXIN, Allgemeiner Teil I, 20/49.

⁷⁵⁶ Bu Kanunu 56. maddesine göre, "*Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir.*"

tedbirinin uygulanmasına *çocuk hakimi* karar verebilir (3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı **Çocuk Koruma Kanunu**, m. 7). Çocuk hakimi, çocuğun içinde bulunduğu aile koşullarını göz önünde bulundurarak çocuk hakkında güvenlik tedbiri olarak koruyucu ve destekleyici tedbirlerden birine veya birkaçına karar verme hususunda takdir yetkisine sahiptir.

2) İkinci Grup Yaş Küçükleri

Kanun, belli bir yaş grubuna giren çocuklar açısından algılama ve irade yeteneğinin her somut olayda tetkik edilmesi gerektiğini ve varılan sonuca göre, çocuk hakkında güvenlik tedbirine veya cezaya hükmolunması gerektiği yönünde düzenleme içermektedir (m. 31, f. 2). Kanuna göre, bu yaş grubunu, fiili işlediği sırada oniki yaşın tamamlanmış ve fakat onbeş yaşını doldurmamış olan çocuklar oluşturmaktadır.

Bu yaş grubuna giren çocuklar, genellikle işledikleri fiilin bir haksızlık teşkil ettiğinin şuurunda olmakla beraber,⁷⁵⁷ bazı hallerde bu fiili işlemekten kendini aliko-

3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı *Çocuk Koruma Kanununun* 11'inci maddesi hükmüne göre, “Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır.”

Çocuklarla ilgili koruyucu ve destekleyici tedbirler, bu Kanunun 5'inci maddesinde belirlenmiştir:

“(1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;

- a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
- b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,
- c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,
- d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına,
- e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,

Yönelik tedbirdir.

(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur.

(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte veli veya vasisinin ya da bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin bertaraf edileceğinin anlaşılması hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uygulanmasında, çocuk hakkında birinci fıkrafta belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebilir.”

⁷⁵⁷ Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 11.4.2019 tarihli ve E. 2019/1485, K. 2019/7068 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; ikinci grup yaş küçüğü olan S, arkadaşı F'nin işlediği hırsızlık suçundan elde ettiği eşyayı sakladığı yeri öğrenir. Ancak, bu durumla ilgili olarak kimseye bilgi vermez.

yamamaktadır; bir başka ifadeyle, belirli haksızlıklar açısından davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirme (irade) yeteneği zayıflamakta ve hatta, bazı durumlarda tamamen ortadan kalkabilmektedir. Örneğin, bu yaş grubuna giren çocuğun işlediği hırsızlık suçu açısından kusur yeteneğine sahip olduğunu kabul edebilmekle beraber; ergenlik döneminin etkisiyle işlediği cinsel motifli suçlar açısından irade yeteneğinin önemli ölçüde zayıfladığını ve dolayısıyla, kusur yeteneğinin azaldığını ve hatta, bazen tamamen kalktığını rahatlıkla söyleyebiliriz⁷⁵⁸.

Yeni TCK'nın düzenleme biçimine göre;

“Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fülle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis

S hakkında, işlenmiş bir suça ilişkin delillerin saklandığı yeri bildirmediği iddiasıyla, TCK'nın “Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme” suçunun tanımlandığı 284. maddesi hükümleriyle cezalandırılması talebiyle kamu davası açılır.

İlk Derece Mahkemesi, S'nin söz konusu suçu işlediğini kabul ederek, hakkında mahkûmiyet hükmü kurmuştur.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, TCK, m. 284 de tanımlanan suçun cezasının üst sınırına göre, TCK, m. 66, f. 1, bent e; m. 66, f. 2; m. 67, f. 4 hükümlerinde öngörülen 6 yıllık **zamanaşımının dolmuş bulunması sebebiyle**, bu mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Hukuki değerlendirmemiz: Yargıtay 2. Ceza Dairesinin bozma kararında, ikinci grup yaş küçüğünün bir başkanının işlemiş bulunduğu hırsızlık suçundan elde ettiği malı saklamış olduğu yerle ilgili olarak bildirim yükümlülüğünün olduğunun bilincinde olup olmadığının tartışılması, önemli bir eksikliklerdir.

⁷⁵⁸ Bu yaş grubuna giren çocukların kusur yeteneği açısından aranacak hususlara ilişkin gerek 765 s. TCK'ndaki gerek 5395 s. Çocuk Koruma Kanunu ile yürürlükten kaldırılan (m. 48) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunundaki ifadeler eksik ve hatta kısmen doğru değildi. Şöyle ki; 765 s. TCK'nın 54'üncü maddesinde sadece “*farik ve mümeyyiz olma*”ktan bahsedilmekteydi. Bu iki kavram, eş anlamlı olup, iki ayrı şeyi ayırd eden anlamına gelmektedirler ve bizim kullandığımız algılama yeteneğine (idrak kabiliyetine) tekabül etmektedirler. Fakat, neyin idrak edileceği, ayırd edilecek hususun ne olduğundan bahsedilmemektedir. 765 s. Kanunun 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise, işlenen “*fiilin suç olduğunu(n) fark ve temyiz*” edilmesi ibaresine yer verilmişti. Bu ifadeye göre, ikinci yaş grubuna giren çocuk işlediği fiilin “suç” olduğunu bilmelidir ki, kusur yeteneğinin varlığını kabul edebilelim. 2253 s. ÇMK'nun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında bu konuda nisbî bir düzeltme yapılmıştı. Buna göre, kişi “işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme” kabiliyetine sahip olmalıdır; yani idrak edilmesi gereken şey, *işlenen fiilin* hukuki anlam muhtevasıdır. Her iki düzenleme açısından eksiklik teşkil eden diğer husus; işlenen fiilin hukuki anlam muhtevasını idrak edebilme kabiliyetinin yanı sıra, kişinin bu doğrultuda hareketlerini yönlendirebilme (irade) kabiliyetine yer verilmemiş olmasıydı. Halbuki bu yaş grubuna giren çocukların işledikleri fiillerde, algılama yeteneğinin varlığından ziyade, irade yeteneğinin azalması ve hatta, yitirilmesi önemli rol oynamaktadır.

cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.” (m. 31, f. 2).

Bu yaş grubuna giren çocuğun işlediği fiille ilgili olarak kusur yeteneğinin olup olmadığına bizzat hakim karar verecektir. Görevlendirilen bilirkişi, çocuğun işlediği fiille ilgili olarak kusurluluğun iki unsurunu oluşturan algılama ve irade yeteneğinin varlığını tespitte yetkili değildir. Bilirkişi ancak çocuğun içinde bulunduğu aile ortamı, sosyal çevre koşulları, gördüğü eğitim, fiziksel ve ruhsal gelişimi hakkında bir rapor düzenleyebilir. Ancak, bu rapor içeriğinde, somut fiille ilgili olarak çocuğun kusur yeteneğinin olup olmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunulmayacaktır. Hakim, bu yaş grubuna giren çocuğun kusur yeteneğinin olup olmadığını takdir ederken, görevlendirdiği bilirkişinin hazırlamış bulunduğu raporda yer verilen gözlem, tespit ve değerlendirmeleri göz önünde bulundurur. Nitekim, 5395 s. ÇKK’nda suça sürüklenmiş “*çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren inceleme yaptırılır. Sosyal inceleme raporu, çocuğun, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz önünde bulundurulur.*” (m. 35, f. 1) hükmüne yer verilmiştir⁷⁵⁹.

Mahkeme tarafından bu yaş grubuna giren çocuğun işlediği fiille ilgili olarak kusur yeteneğinin olmadığı yargısına varılması halinde, çocukla ilgili olarak “*kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.*” (5277 s. CMK, m. 223, f. 3, bent a)⁷⁶⁰.

Bu nedenle, kusur yeteneğinin bulunmadığı yargısına varılan çocukla ilgili olarak mahkemece beraat kararı verilemez. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun verdiği bir Karardaki şu ifadeler, yeni TCK ve CMK düzenlemeleriyle uyum içindedir:

⁷⁵⁹ Ancak belirtmek gerekir ki, ikinci grup yaş küçüğü olan çocukların işledikleri fiille bağlantılı olarak ceza sorumluluğunun olup olmadığı yönünde yapılan tespitte ve bu tespitte izlenen yöneme ilişkin uygulamamız, bilimsel esaslara ve yukarıda açıkladığımız kanuni düzenlemelere uygun değildir (Ayrıntılı bilgi için bkz. AYDIN Murat: *Türkiye’de Çocuk Mahkemeleri Kurulmalıdır!*, in: Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Çocuk(ça) Adalet?, 13-19 Eylül 2013, Tebliğler, Editör Adem Sözüer, sh. 60 vd.).

⁷⁶⁰ Yeni CMK’nın 223’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre;

“Sanık hakkında;

a) *Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması,*

b) *Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat başlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,*

c) *Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,*

d) *Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi,*

Hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.”

«Suç tarihinde 11 yaşını bitirip 15 yaşını doldurmamış bulunan sanıklar hakkında yapılan soruşturmada, üzerlerine atılı suç sabit değilse veya eylem suç teşkil etmiyorsa beraatlerine, suçlarının sabit olması ve işledikleri suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olmamaları halinde ise, "haklarında ceza tertibine yer olmadığına" karar verilecektir. Ceza tertip etmemek başka; suçsuzluğu öngören beraat ise daha başka, hukuki yapıları ve sonuçları ayrı iki farklı karar türüdür»⁷⁶¹.

Ancak, bu halde, yani işlediği suçtan dolayı kusur yeteneği olmayan çocuk hakkında mahkemece çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Dikkat edilmelidir ki, bu mahkeme, çocuk mahkemesidir (5395 s. ÇKK, m. 25, 26, 27). Birinci yaş grubuna giren çocuklardan farklı olarak, ikinci yaş grubuna giren çocuklarla ilgili olarak mahkeme çocuklara özgü güvenlik tedbirine hükmedip etmeme konusunda takdir yetkisine sahip değildir.

İkinci yaş grubuna giren çocuğun, işlediği haksızlıkla ilgili olarak algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin varlığı halinde, kusurlu olduğu muhakkaktır. Bu çocuklar açısından nasıl bir yaptırım sisteminin tatbik edileceği, izlenen ceza siyasetine göre tayin edilecektir. İşlediği suç dolayısıyla kusurlu olduğu yargısına varılan çocuk hakkında ceza yaptırımı uygulanabilir. Ancak, bu kişiler hakkında uygulanacak cezada, indirim yapılması gerekmektedir. Bu indirim miktar ve oranları 31'inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenmiştir. Cezada yapılacak olan bu indirim, 61'inci maddede belirlenen usul izlenerek, bu maddenin beşinci fıkrasındaki sıraya göre yapılacaktır.

Ancak belirtmek gerekir ki; “daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, ... fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış ... bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, (50'nci maddenin) birinci fıkra(sın)da yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.” (m. 50, f. 3). Başka bir ifadeyle, işlediği fiille ilgili olarak kusur yeteneği olan çocuk hakkında hükmolunan hapis cezası kısa süreli ise; bu cezanın, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınmamıştır⁷⁶².

Keza, “işlediği suçtan dolayı (üç) yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen (çocuğun) cezası ertelenebilir.” (m. 51, f. 1).

⁷⁶¹ CGK., 4.12.1989, 3-330/386 (YKD., Kasım-1990, sh. 1684 vd. [1686]).

⁷⁶² “Suç tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olan faile verilen hapis cezası miktarı itibarıyla kısa süreli olup, bu cezanın TCK'nın 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince zorunlu olarak aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilebilmesi için, failin **daha önce hapis cezası cinsinden mahkûmiyetinin bulunmaması** gerekmektedir.

Suçta sürüklenen sanık çocuğun sabıkasında yer alan **adli para cezasına, hükümün açıklanmasının geri bırakılmasına ve hapis cezasına seçenek yaptırımlara ilişkin ilamların** TCK'nın 50. maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına engel oluşturmayacağı konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır.”: CGK, 10.3.2015, E. 2013/8-816, K. 2015/39.

Belirtmek gerekir ki, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmesi halinde, bu mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak TCK'nın 53'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaz (m. 53, f. 4).

Ayrıca, “*fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.*” (m. 58, f. 5).

Mahkeme, işlediği suçtan dolayı kusur yeteneği bulunan çocukla ilgili olarak CMK'nın 231. maddesi hükümlerine göre *hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına* karar verebilir⁷⁶³.

Hatta, Cumhuriyet savcısı bu çocukla ilgili olarak CMK'nın 171. maddesi hükümlerine göre *kamu davasının açılmasının ertelenmesine* de karar verebilir⁷⁶⁴.

Ancak, işaret etmek gerekir ki, çocuk hakkında hükmolunan ceza yaptırımlarına bağlanan hukuki sonuçların farklı olmasının ve bu cezalarla ilgili olarak özel infaz rejiminin benimsenmesinin, kişinin kusurluluğuyla, kusur ehliyetiyle alâkası bulunmamaktadır⁷⁶⁵.

3) Üçüncü Grup Yaş Küçükleri

Bedenî, fizikî olgunluk sürecini tamamlamış ve aynı zamanda ruhî bakımdan malûliyeti olmayan, akletme kabiliyetine sahip kişiler, normal şartlarda kusur yeteneğine sahiptirler. Ancak, ceza siyaseti mülâhazalarıyla, tekrar topluma kazandırılmaları ve bir daha suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla; belli yaşlardaki gençlerin işledikleri suçlar açısından idrak ve irade kabiliyetine sahip olmalarına ve dolayısıyla, kusurlu bulunmalarına rağmen, mahkûm olacakları cezaların tür ve miktarları, bu cezaların nasıl infaz edileceği hususlarında keza kanunlarda özel düzenleme yapılması cihetine gidilmektedir. Yeni TCK, 765 s. Kanunda olduğu gibi, bu yaş grubunu fiili işlediği sırada 15 yaşını ikmal etmiş ve fakat, henüz 18 yaşını doldurmamış çocuklar olarak belirlemiştir (m. 31, f. 3)⁷⁶⁶.

⁷⁶³ 5395 s. Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi ceza sorumluluğu olan çocuklar bakımından özel olarak düzenlenmişti. Ancak, 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle söz konusu müessese Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenince (m. 231), ÇKK'nın yine 5560 s. Kanunla değiştirilen 23. maddesinde sadece atıf hükmüne yer verilmiştir.

⁷⁶⁴ 5395 s. ÇKK'nın 19. maddesinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesi ceza sorumluluğu olan çocuklar bakımından özel olarak düzenlenmişti. Ancak, 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle söz konusu müessese Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenince (m. 171), ÇKK'nın yine 5560 s. Kanunla değiştirilen 19. maddesinde sadece atıf hükmüne yer verilmiştir.

⁷⁶⁵ Aynı mealde ROXIN, Allgemeiner Teil I, 20/52, 54.

⁷⁶⁶ Yeni TCK'na ilişkin Hükümet Tasarısında ise bu grup çocuklar, “*küçük*”ler olarak isimlendirilmişti (m. 100, f. 3). “*Küçük*” kelimesi bir sıfattır ve izafi bir anlam ifade eder. Ağırlık itibarıyla, boy itibarıyla, yaş itibarıyla vs. küçüklükten bahsedilebilir. Yani, kanaatimizce, genel olarak “*küçük*” diye

Bu yaş grubuna giren çocuğun işlediği suçla ilgili olarak kusur yeteneğinin olup olmadığını araştırmaya gerek bulunmamaktadır. Ancak, buna rağmen, suça sürüklenmiş bu “*çocuklar hakkında (da) mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren inceleme yaptırılır.*” (5395 s. ÇKK, m. 35, f. 1). Bu sosyal inceleme raporu, çocuk hakkında,

a) hükmolunacak cezanın bireyselleştirilmesinde (m. 61) ve bu kapsamda

aa) hapis cezasına seçenек olarak adli para cezasının öngörüldüğü suçlarda çocuk hakkında hapis veya adli para cezasına hükmedilmesinde,

bb) takdiri indirim nedenlerinden yararlandırılmasında (m. 62),

cc) hükmolunan kısa süreli hapis cezasına seçenек yaptırımın belirlenmesinde (m. 50),

dd) hükmolunan hapis cezasının ertelenmesinde ve denetim süresi içinde hakkında uygulanacak denetimli serbestlik tedbirinin belirlenmesinde (m. 51),

b) hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde (5395 s. ÇKK, m. 23 yollaması ile CMK, m. 231) ve ayrıca,

c) kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmesinde (5395 s. ÇKK, m. 19 yollaması ile CMK, m. 171),

göz önünde bulundurulur.

Üçüncü yaş grubuna giren çocuk hakkında uygulanacak cezada, indirim yapılması gerekmektedir. Bu indirim miktar ve oranları 31'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenmiştir. Cezada yapılacak olan bu indirim, 61'inci maddede belirlenen usul izlenerek, bu maddenin beşinci fıkrasındaki sıraya göre yapılacaktır.

Ancak belirtmek gerekir ki; “*daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, ... fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış ... bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, (50'nci maddenin) birinci fıkra(sın)da yazılı seçenек yaptırımlardan birine çevrilir.*” (m. 50, f. 3). Başka bir ifadeyle, işlediği fiille ilgili olarak kusur yeteneği olan çocuk hakkında hükmolunan hapis cezası kısa süreli ise; bu cezanın, kısa süreli hapis cezasına seçenек yaptırımlardan birine çevrilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınmamıştır.

Keza, “*işlediği suçtan dolayı (üç) yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen (çocuğun) cezası ertelenebilir.*” (m. 51, f. 1).

Belirtmek gerekir ki, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmesi halinde,

bir kavramdan bahsedilemez. 2253 s. ÇMK'da da "küçük" deyimine yer verilmiş ve bununla "suçu işlediği tarihte henüz 15 yaşını bitirmemiş kimseler" ifade edilmişti (m. 4).

bu mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak TCK'nın 53'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaz (m. 53, f. 4).

Ayrıca, “*fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.*” (m. 58, f. 5).

Mahkeme, işlediği suçtan dolayı kusur yeteneği bulunan çocukla ilgili olarak 5395 s. ÇKK'nun 23. maddesinin yollaması ile CMK'nın 231. maddesi hükümlerine göre *hükümün açıklanmasının geri bırakılmasına* karar verebilir.

Hatta, Cumhuriyet savcısı bu çocukla ilgili olarak ÇKK'nun 19. maddesinin yollaması ile CMK'nın 171. maddesi hükümlerine göre *kamu davasının açılmasının ertelenmesine* de karar verebilir.

Ancak, tekrar belirtmek gerekir ki, çocuk hakkında hükmolunan ceza yaptırımlarına bağlanan hukuki sonuçların farklı olmasının ve bu cezalarla ilgili olarak özel infaz rejiminin benimsenmesinin, kişinin kusurluluğuyla, kusur ehliyetiyle alâkası bulunmamaktadır⁷⁶⁷.

Çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması durumunda, kusur yeteneği olmadığı için hakkında cezaya hükmolunamayacaktır. Ancak, bu çocuklarla ilgili olarak akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin mi, yoksa çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin mi uygulanacağı konusunda oluşabilecek tereddütleri gidermek amacıyla 5395 s. ÇKK'na bir hüküm konmuştur (m. 12):

“Suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren çocuklar hakkında, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.”

B. Akıl Hastalığı

Akletmek, şahsiyet sahibi insanın algılama yeteneğiyle alâkalı bir *fonksiyondur*; bir başka ifadeyle, belli verilerden insanın belli sonuçlar çıkarabilme yeteneğidir⁷⁶⁸. Bunun bir başka ifadesi olan düşünme, kendi varlığının şuurunda olan insanın, içinde yaşadığı doğal ve sosyal çevredeki vakıaları, olguları algılaması ve bunlardan belli sonuçlar çıkarması sürecidir. Düşünebilmek için, insanın önce anlama ve algılama kabiliyetinin gelişmiş olması gerekir. Davranışlarının hukuki anlam muhtevasını kavrama açısından insanın anlama ve algılama yeteneğinin (idrak kabiliyetinin) gelişmiş olmasının yanı sıra; davranışlarını da bu doğrultuda yönlendirebilme yeteneğine (irade kabiliyetine) sahip olması gerekmektedir.

⁷⁶⁷ Aynı mealde ROXIN, Allgemeiner Teil I, 20/52, 54.

⁷⁶⁸ Akıl ve idrak kavramları hakkında bilgi için bkz. KAUFMANN, Arthur: *Rechtsphilosophie in der Nach-Neuzeit*, 2. Auflage, Heidelberg, 1992, sh. 14 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: *İnsan Haklarının Felsefi Temeli*, in: İnsan Hakları, 2. bası, İstanbul, 1995, sh. 45 vd.

Ancak, insan, akıl hastalığı denen bazı psikişik bozukluklar nedeniyle, davranışlarının hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneğinden veya davranışlarının hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğinden yoksun olabilmektedir. Bu nedenledir ki, maruz kaldığı akıl hastalığının etkisinde kalarak suç teşkil eden bir fiil işleyen kişinin kusur yeteneğinin olmadığı kabul edilmektedir⁷⁶⁹.

Meselâ, *şizofreni* adı verilen akıl hastalığı halinde, kişide düşünce bozuklukları mevcuttur. Hasta, düşündüğü şeyin başkaları tarafından kendisine emredildiğini zanneder. Ancak, ifade etmek gerekir ki; şizofreni akıl hastasının düşünceleri anlaşılmaz ve bütünüyle saçma değildir. Dikkatli izlenmesi halinde kişinin davranışları ile düşünceleri arasında belli bir mantıkî bağlantının olduğu görülür. Şizofreni akıl hastalığında ayrıca işitme ve görme halüsinasyonları görülür. Kişi, gerçekte mevcut olmayan birtakım sesler duyar, cisimleri farklı görür ve farklı algılar; çevresindeki kişileri düşman olarak görebilir. Kişi, bu halüsinasyonlar ile diyalog kurar, söyleşir ve genellikle onlardan, karşı koymakta güçlük çektiği emirler alır⁷⁷⁰.

Bu halüsinasyon ve illüzyonların etkisindeki şizofren hasta, ani olarak saldırgan hareketlere girişebilmekte, meselâ adam öldürme suçunu sebepsiz yere ve soğukkanlılıkla işleyebilmektedir. Kişi, çevredeki eşyayı kırıp dökme gibi, şiddet girişimlerinde bulunur.

Bir affektif psikoz olan *mani* hastası, hastalığın had safhasında artık kimseyi dinlemez; her davranışını gerekli ve mantıklı bulur ve düşündüğü gibi hareket eder. Kişide korku ve kaygı yoktur. *Melankoli* psikozunda ise, kişiye şiddetli sıkıntı ve keder hakimdir. Kendisini suçlu gören, itham eden, günahkâr sayan hasta kişi, bir an

⁷⁶⁹ “Kusur yeteneği, 5237 sayılı TCY’nın 31/2 ve 32/1. maddelerinde dolaylı bir biçimde tanımlanmıştır. Bu hükümler uyarınca; **fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını buna göre yönlendirme yeteneğinin bulunması** halinde kusur yeteneğinin varlığı kabul edilmiştir. Kusur yeteneğinin iki belirgin görünümü vardır. Bunlardan ilki; **kişinin işlediği fiilin hukuki anlamını ve sonuçlarını anlayabilme yeteneği**, diğeri ise; **fiilin hukuki anlam ve sonucunu kavrayan kişinin davranışlarını bu algılaması doğrultusunda ve hukuk düzeninin gereklerine uygun olarak yönlendirme yeteneğinin bulunmasıdır**. Algılama ve irade yeteneği de denilen bu iki ögenin kişide bir arada bulunmaması veya bu yeteneklerinde azalma meydana gelmesi durumunda ise kusur yeteneğinin tam olmadığı kabul edilmelidir.

Yeni ceza adalet sistemimizde akıl hastalığı; kusur yeteneğini etkilemesi nedeniyle, ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden birisi olarak düzenlenmiştir. Buna göre, ortada tüm unsurlarıyla oluşmuş bir suç bulunmakta ise de; akıl hastası olduğu saptanan sanık, işlemiş bulunduğu fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamayacak durumda olduğundan, bu suçun işlenmesinden dolayı hukuki anlamda “kınanamaz”, yani sorumlu tutulup cezalandırılmaz. Dolayısıyla, 5237 sayılı Yasanın 32/1. maddesi gereğince bu durumdaki sanığa ceza tayin edilmesi mümkün bulunmadığından, 5271 sayılı Yasanın 223/3-a maddesi uyarınca “ceza verilmesine yer olmadığı” hükmünün verilmesi gerekir. Ancak, sanığa ceza verilemiyor olması, sanık hakkında 5237 sayılı Yasanın 57. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri uygulanmasına engel değildir.”: CGK, **20.3.2012**, E. 2011/1-451, K. 2012/115. Ayrıca bkz. CGK, **30.10.2014**, E. 2013/8-119, K. 2014/448; CGK, **9.2.2016**, E. 2014/8-796, K. 2016/51.

⁷⁷⁰ ÜNVER, Yener: *Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi* (yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1989, sh. 14.

önce ölmesi gerektiği inancındadır; bu nedenle rahatlıkla intihar edebilmekte ve hatta, aile fertlerine karşı acımasızca öldürme suçu işleyebilmektedir.

Paranoya akıl hastalığında kişi belli bir hezeyanın etkisiyle meselâ kıskançlık veya haklı olma gibi bir saplantı içinde olabilir. İdrak kabiliyetindeki bozukluğun etkisiyle kişi, öldürme, yaralama veya şiddet ihtiva eden sair suçları işleyebilir.

Kusur yeteneğine etkisi bakımından *sar'a* hastalığı (*epilepsi*) önem taşımaktadır. Hangi türden olursa olsun, sar'a nöbeti şuur kaybına sebebiyet vermektedir. Bu nöbetlerde genellikle depresyon, korku ve kızgınlık halleri, affektif bozukluklar, zihin fonksiyon bozuklukları, algı kusurları ve davranış bozuklukları görülür. Şuur bozukluğuna sebebiyet veren bu nöbetler sırasında kişi saldırgan hareketlerde bulunabilir, öldürme veya yaralama gibi suçlar işleyebilir; intihar edebilir. Sar'a, kişide artan ve frenlenemeyen bir şehvet hissine sebebiyet verebilir. Ancak, işaret etmek gerekir ki, kişide şuur kaybına sebebiyet vermeyen sar'a nöbetleri de mevcuttur.

Derecesi ne olursa olsun *zekâ geriliği* (*oligofreni*) halinde kişinin algılama yeteneği genel olarak zayıflar, yavaş işler. Öğrenme yeteneğindeki zayıflık dolayısıyla ahlak normlarının, topluma hakim olan değer normlarının anlamını kavrayamazlar. Bu nedenle, zekâ geriliği olan kişilerin irade yetenekleri de zayıftır. Kolaylıkla telkin altında kalıp suç işleyebilirler. Bu kişiler, davranışlarının anlam ve sonuçlarını kavrayamadan hırsızlık, cinsel nitelikli suçlar, öldürme, yaralama veya yalan şahitliği gibi suçları kolaylıkla işleyebilirler.

Genellikle 65-70 yaşlarında başlayan *yaşlılık bunaklığı* (*demans senil*) halinde zekâ işlevlerinde bir durgunluk ve zaaf baş gösterir. Kişi, çoğunlukla küçük çocuklara yönelik olarak cinsel sapıklıklarda bulunur. Bu fiiller, bir anlık şehvet hissini artırması nedeniyle işlenir. Basit hırsızlık, hakaret, şiddet kullanma gibi fiiller sıklıkla işlenir. Suçlar, anî bir kararla işlenir; tasarlama hali yoktur. Eski tarihli olaylar canlı bir şekilde nakledilmekle birlikte; yeni tarihli olaylar hatırlanmaz, çabuk unutulur.

“*Hırsızlık hastalığı*” diye anılan kleptomanide kişi içten gelen anî ve karşı konulmaz dürtülerle hırsızlık suçunu işler. Çalınan şeylerin değerinin olup olmaması önemli değildir. Kişinin satın alma gücünün varlığının da bir önemi yoktur. Kişi çok daha değerli şeyleri çalma imkânına sahip olsa dahi, dürtülerinin yöneldiği eşyayı çalmayı tercih eder.

Keza, uyurgezerlik halinde veya hipnotik telkin altında gerçekleştirilen davranışlar açısından kişinin şuurunun varlığından bahsedilemez. Kanaatimizce bu gibi hallerde kişinin kusur yeteneğinin yokluğundan ziyade; gerçekleştirdiği davranışların hukuki anlamda fiil niteliğini taşımadığını söylemek daha doğru olur.

Ancak, işaret etmek gerekir ki; kişinin algılama ve irade yeteneği üzerinde işlediği fiil dolayısıyla sorumluluğu açısından önem arzedecek bir etkisi olmayan *nevrotik*

bozukluklar veya *psikopati* halinde kişinin kusur yeteneğinin var olduğunu kabul etmek gerekir⁷⁷¹. Ancak, bu kişilerin resosyalizasyonu açısından tayin edilecek cezaî müeyyide ve bunun infaz biçimi bu kapsamda değerlendirilecek bir husus değildir.

Yeni TCK'nın 32. maddesinde “*akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.*” (f. 1, birinci cümle) denilmek suretiyle, kişinin ceza hukuku sorumluluğu bakımından, akıl hastalığının davranışları üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmuştur. Bu bakımdan önemli olan, akıl hastalığının kişinin algılama ve irade yeteneği üzerindeki etkisidir.

Buna göre, suç teşkil eden bir fiil işleyen kişinin akıl hastası olup olmadığının, akıl hastası ise bu hastalığın kişinin davranışları üzerinde ne tür etkilerinin olabileceğinin, bu hastalığın somut olayda kişinin işlediği fiile ilişkin algılama ve ya irade yeteneği üzerindeki etkisinin araştırılıp belirlenmesi gerekir.

Kişinin akıl hastası olup olmadığı, psikiyatri biliminin verileri çerçevesinde uzman kişiler tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, akıl hastası ise, bu hastalığın kişinin davranışları üzerinde ne tür etkilerinin olabileceğinin de belirlenmesi gerekir. Ancak, işaret etmek gerekir ki, bu belirleme, somut olayda işlenen fiille ilgili olarak yapılmamalıdır. Bu belirleme genel olarak yani, somut olaydan bağımsız olarak yapılmalıdır. Ayrıca, kişinin ne zamandan beri bu hastalığa maruz kaldığının da mümkün olduğunca belirlenmesi gerekir. Çünkü, ceza hukuku sorumluluğu bakımından önemli olan, fiilin işlendiği sırada akıl hastası olup olmamasıdır. Kişi, fiili işledikten sonra ceza muhakemesi sürecinde ve hatta, cezanın infazı sürecinde de akıl hastalığına maruz kalabilir. Bütün bu hususlar, psikiyatri biliminin verileri çerçevesinde, uzman hekimler tarafından tespit edilecektir. Buna karşılık, somut olayda işlenen fiille bağlantılı olarak kişinin bu akıl hastalığı nedeniyle algılama veya irade yeteneğinin etkilenmiş olup olmadığını, yani kusurlu olup olmadığını takdir yetkisinde olan ise, münhasıran mahkemedir. Mahkeme, bu değerlendirmeyi yaparken, uzman hekimler tarafından düzenlenen rapor içeriğini göz önünde bulunduracaktır.

765 s. Kanundan farklı olarak **yeni TCK'da, akıl hastalıkları, “tam -” veya “kısmî akıl hastalığı” olarak ayırma tabi tutulmamıştır**⁷⁷². Bir insan ya akıl

⁷⁷¹ “Ruh sağlığı bilimine göre, kişide kaygı, korku, gerilim ve sıkıntı halini ifade eden anksiyete, kişinin dış ortama uyumu sırasında geliştirdiği koruyucu bir tepki olarak kabul edilmiş, Türkçede de “kaygı, bunaltı, iç sıkıntısı, stres” gibi sözcüklerle tanımlanmaya çalışılmıştır. Anksiyete, her insan tarafından bazı durumlarda yaşanabilecek bir duygu olup, esasen; denetim dışına çıkıp kişinin işlevselliğini aksatmadığı sürece insanın gerek bireysel gerekse toplumsal adaptasyonu için belli ölçüde anksiyetenin de gerekli olduğu konunun uzmanları tarafından kabul edilmektedir.” Bu itibarla **anksiyete**, ceza sorumluluğunu etkileyen bir akıl hastalığı olarak kabul edilmemiştir. (CGK, 20.3.2012, E. 2011/1-451, K. 2012/115).

⁷⁷² Yeni TCK'na ilişkin Hükümet Tasarısında da bu ayırımdan sarfınazar edilmiştir (m. 36; '89 Öntasarısı, m. 34; '97 Öntasarısı, m. 35).

hastasıdır veya değildir. Hukuken önemli olan, kişinin malûl olduğu akıl hastalığının algılama ve irade yeteneği üzerinde etkili olup olmamasıdır⁷⁷³.

Malûl olduğu akıl hastalığının kişinin işlemiş bulunduğu somut fiil açısından algılama veya irade yeteneğini etkilemesi gerekmektedir. Kişi belli bir akıl hastası olmakla birlikte, işlediği fiile ilişkin algılama veya irade yeteneği üzerinde bu hastalığın herhangi bir etkisi bulunmayabilir. Meselâ, kleptomani akıl hastası olan kişi bir alışveriş merkezinde cüz’i değerdeki bir şeyi çalsa, bu fiil açısından irade yeteneğinin olmadığını pekala söyleyebiliriz⁷⁷⁴. Ancak, bu kişi kasten öldürme suçunu işlerse, malûl olduğu akıl hastalığı bu fiille ilgili olarak ne algılama yeteneğini ne de irade yeteneğini etkiler.

Bu bakımdan Kanunda, maruz kalınan “*akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilme*”yeceği kabul edilmiştir. Başka bir deyişle, akıl hastalığı nedeniyle kişinin ceza sorumluluğunun olmadığını kabul edebilmek için; a) mevcut akıl hastalığının, kişinin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğini ortadan kaldırması gerekir; b) işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamakla beraber, maruz kaldığı akıl hastalığı nedeniyle, kişinin bu fiille ilgili olarak davranışlarını hukukun icapları doğrultusunda yönlendirme yeteneği ortadan kalkmış veya önemli ölçüde azalmış olması gerekir.

Akıl hastası olması nedeniyle işlediği fiille ilgili olarak kusur yeteneği ve ceza sorumluluğu olmayan kişi hakkında, mahkemece akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmolunur. Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri, yeni TCK’nın 57. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Yeni TCK’nın 32. maddesinin ikinci fıkrasına göre, maruz kaldığı akıl hastalığı kişinin işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirme yeteneğini önemli derecede olmamakla birlikte, azaltmış olabilir. Bu gibi durumlarda mahkeme, kişi hakkında cezaya hükmetmekle birlikte, cezasında indirim yapma hususunda bir yetki ile donatılmaktadır. İşlediği fiille ilgili olarak algılama yeteneğine sahip olmasına rağmen psikopati gibi akıl hastalıklarında kişinin azalmış da olsa kusur yeteneğinin ve ceza sorumluluğunun olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak, bu durumda hükmolunan ceza, infaz kurumunda değil de, “*süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir*.” Bu konuda karar verme yetkisi, hükmü veren mahkemeye aittir. Mahkeme, kişi hakkında hapis cezasına hükmederken, bu cezanın akıl has-

⁷⁷³ Ayrıca bkz. İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 221 vd.

⁷⁷⁴ 2. CD., 17.2.1956, 3184/2295 (Erem, Adalet Psikolojisi, sh. 149). Ayrıca bkz. ÜNVER, Akıl Hastalığı, 136 vd.

ta-larına özgü güvenlik tedbiri olarak infazına karar verebilir. Hükmü veren mahkeme bilahare, yani hükmolunan hapis cezasının infazı sürecinde de, kalan kısmının akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak infazına karar verebilir. Bu hususta karar verirken esas alınması gereken amaç, mümkün olduğunca ceza infaz kurumuna sokmadan, kişinin toplum açısından oluşturduğu tehlikeyi önlemek ve mahkum olduğu hapis cezasını akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak infazı suretiyle tekrar topluma kazanılmasını sağlamaktır. Dikkat edilmelidir ki, hükmolunan hapis cezasının kısmen veya tamamen akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak infazına karar verilmesi halinde, mahkumiyet, bir **ceza mahkumiyeti** olarak varlığını muhafaza etmektedir. Dolayısıyla, hapis cezasına mahkumiyete bağlı hak yoksunluğu gibi hukuki sonuçlar bu durumda da doğacaktır. Başka bir deyişle, bu durumda yaptırımın türü değişmemektedir. Sadece hükmolunan hapis cezasının infaz suretinde bir değişiklik söz konusu olmaktadır.

Ayrıca belirtilmelidir ki, hükmolunan hapis cezasının, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak infazına karar verildikten sonra, hükümlünün bu güvenlik tedbirinin gereklerine aykırı davranması nedeniyle, mahkemece infaz kurumunda çektirilmesine de karar verilebilir.

Bu düzenlemeden, yeni TCK'da da "tam –" veya "kısmi akıl hastalığı" ayrımının muhafaza edildiği şeklinde yanlış bir sonuç⁷⁷⁵ çıkarılmamalıdır. Bu sistemde bir kişi ya akıl hastasıdır veya değildir. Kişinin akıl hastası olup olmadığı, ne tür bir akıl hastalığına maruz kaldığı, bu hastalığın kişinin davranışları üzerindeki muhtemel etkileri, psikiyatri biliminin verileri çerçevesinde bilirkişi uzman hekim tarafından belirlenecektir. Ancak, mevcut olan akıl hastalığının somut olayda işlediği fiille ilgili olarak kişinin ceza hukuku sorumluluğunun belirlenmesindeki etkisini, münhasıran mahkeme takdir ve tayin edecektir.

C. Sağır ve Dilsizlik

İnsanın işitme yeteneğine doğuştan sahip olmaması veya küçük yaşta bu yeteneği yitirmesi dolayısıyla, konuşma yeteneği de gelişmez. İşitme yeteneğine hiç sahip olmayan insanın algılama yeteneği de yeterince gelişmez.

Sağır ve dilsizlerin kusur yeteneği ve cezaî sorumluluğu konusunda çeşitli sistemler kabul edilmektedir.

Bir sistemde sağır ve dilsizlikle ilgili olarak kanunda özel bir hükme yer verilmez. Ancak, sağır ve dilsizlik halinin somut olayda kişinin kusur yeteneği üzerinde etkili olup olmadığını araştırmak ve sonucuna göre failin cezasında belli bir oranda indirim yapılıp yapılmamasına karar verilmek gerekecektir.

⁷⁷⁵ YARSUVAT/BAYRAKTAR ve diğerleri, sh. 297; TOROSLU, Genel Kısım, 8. bası, sh. 341; CENTEL/ZAHER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 4. bası, sh. 384; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 3. bası, sh.426 vd.

Diğer bir sistemde ise, sağır ve dilsizlikle ilgili olarak kanunda özel bir hükme yer verilmekte ve bu kişilerin sorumluluğu, akıl hastalarının cezaî sorumluluğuna paralel bir şekilde düzenlenmektedir.

Üçüncü sistemde ise, kanunda belli bir yaşa kadarki sağır ve dilsizler hakkında yaş küçüklerine ilişkin hükümlere, belli bir yaştan üzerindeki sağır ve dilsizler hakkında ise, akıl hastalığına ilişkin hükümlere paralel bir düzenleme getirilmektedir. Yeni TCK’da bu sistem kabul edilmiştir⁷⁷⁶.

Kusurluluk bağlamında yapmış bulunduğumuz algılama ve irade yeteneklerine ilişkin açıklamalar dikkate alındığında; yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı dışında, ayrıca “sağır ve dilsizlik” haliyle ilgili olarak Kanunda düzenleme yapılmasına gerek olmadığı anlaşılabilmektedir⁷⁷⁷. Ancak, bu düşüncemize rağmen, yeni TCK’ya ilişkin olarak TBMM Adalet Alt Komisyonunda yapılan çalışmalar sırasında, bu konuda ayrıca düzenleme yapılması gerektiği yönündeki irade benimsenmiştir. Bu irade doğrultusunda, madde metnini yirmibir yaştan doldurulmasına kadar yaş küçüklerine, bu yaştan sonra ise akıl hastalarına ilişkin sorumluluk rejimine göre düzenlemiş bulunmaktayız.

Madde **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir⁷⁷⁸:

“İşitme yeteneğine doğuştan sahip olmayan veya küçük yaşta bu yeteneği tamamen yitiren insanın algılama yeteneği yeterince gelişmez.

Sağır ve dilsizin ceza sorumluluğunun belirlenmesinde, suç oluşturan fiili işlediği sıradaki yaşı, ölçü alınmıştır. Böylece, sağır ve dilsizlerle ilgili olarak, yaş küçüklerinin sorumluluk rejimine paralel bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, sağır ve dilsizlerin algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği daha geç gelişebileceği düşüncesiyle, ayrı bir yaş grubu sınıflandırması yapılmıştır.

Fiili işlediği sırada yirmibir yaşını doldurmuş olan sağır ve dilsizler açısından yaştan ceza sorumluluğu üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı kabul edilmiştir. Ancak, bu kişilerin işledikleri fiil açısından algılama veya irade yeteneğinin olup olmadığı yönünde ortaya çıkabilecek sorunla ilgili olarak, akıl hastalarına ilişkin sorumluluk rejiminin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.”

D. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma

1) “Sebebinde Serbest Hareket” (actiones liberae in causa) Kavramı

Kişi kusur yeteneğine suçu işlediği sırada sahip olmalıdır. Bu itibarla, bir suçun işlenmesinden sonra kusur yeteneğinin ortadan kalkması, bu suç dolayısıyla

⁷⁷⁶ Ayrıca bkz. 765 s. TCK, m. 57, 58; 2253 s. Kanun, m. 12, f. 3.

⁷⁷⁷ Aynı fikir için bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 256 vd.; İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(1), sh. 230 vd.

⁷⁷⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 440.

sorumluluk açısından herhangi bir etki doğurmaz. Ancak, meselâ akıl hastası olan bir kişi hakkında dava açılmaması, açılmış olan davaya devam edilememesi veya hükmolunmuş cezanın infaz edilememesi sorunları, kusur yeteneği ile ilgili hususlar değildir.

Suçun icra hareketlerinin gerçekleştirilişi sırasında kişi kusur yeteneğini yitirebilir. Meselâ, öldürmek amacıyla bıçakla mağdura saldıran fail, ilk bıçak darbesiyle kan tutulmasına maruz kalır. Mağdurun ölümünü sonuçlayan bıçak darbeleri kan tutulması halinde iken ika edilmiştir. Suçun kanunî tanımına uygun son hareketler icra edilirken algılama yeteneğinin yitirilmiş olması, hukuki bakımdan önem arzetmemektedir. Şayet fail, kastettiği neticeyi elde etmiş ise, bilahare, fiilin icrasına başladıktan sonra algılama yeteneğini kaybetmiş olsa bile; (tamamlanmış suç olarak) bu suçtan dolayı sorumlu tutulmalıdır⁷⁷⁹.

Kişi bir suçu işlemeye karar verdikten sonra, bu suçun icrasına henüz başlamadan kusur yeteneği ortadan kalkmış olabilir. Bu gibi durumlarda, *sebebinde serbest hareket* (*actiones liberae in causa*) söz konusudur⁷⁸⁰.

Sebebinde serbest hareketin yegane özelliği, suçun kanunî tanımına uygun fiilin icra edildiği sırada kişinin algılama yeteneğini yitirmiş olmasına rağmen, sorumluluğu cihetine gidilmesidir. Kişi, suçun kanunî tanımına uygun fiili icra etmeden önce algılama yeteneğini yitirmekte ve şuursuz vaziyette iken fiili işlemektedir.

Sebebinde serbest hareketin açıklanmasına ilişkin olarak esasen iki görüş ileri sürülmüştür: 1) “istisna modeli”, 2) “tipiklik modeli”.

“İstisna modeli”ne göre, sebebinde serbest hareket failinin fiili işlediği zaman algılama ve irade yeteneğine sahip olmasını ifade eden kusur prensibinin bir istisnasını teşkil etmektedir. Buna göre, kişi, her ne kadar fiili işlediği sırada şuuru yerinde değilse de, işlediği fiil dolayısıyla cezalandırılabilir.

Bu model, kusursuz ceza olmaz ilkesine aykırılık arzetmektedir. Zira, algılama yeteneğinin yitirilmesine sebep olan davranışın sorumluluğun tayininde değerlendirme dışı bırakılması, kast ve taksirin işlenen fiille bağlantısının inkârını sonuçlamaktadır.

Buna karşılık; “tipiklik modeli”nde ise; işlenen fiilden dolayı sorumluluğun izahında algılama yeteneğinden (şuurdan) yoksun olunan hal değil, algılama yeteneğinin yitirilmesini sonuçlayan davranış, esas alınmaktadır. Bu davranış, kasten icra edilebileceği gibi; gerekli dikkat ve özen gösterilmeksizin, yani taksirle de gerçekleştirilebilir.

Algılama yeteneğinin yitirilmesini sonuçlayan davranışın taksirle işlenmesi halinde, şuursuz olarak işlenen fiilden dolayı sorumluluğun izahında taksire ilişkin

⁷⁷⁹ JAKOBS, Lehrbuch, 8/76. Ancak, *Schroeder*, bu halde failin teşebbüsten dolayı sorumluluğu cihetine gidilmesi gerektiği düşüncesindedir (LK [10], § 16, kn. 33).

⁷⁸⁰ ÇINAR, Ön Kusurluluk, sh. 97 vd., 213 vd.

kurallar esas alınacaktır. Meselâ, eşiyle arasında geçen tartışma dolayısıyla öfkelenen kişi, alkol alarak sarhoş olur. Kişi, daha önceki tecrübelerine göre şuurunu yitirdiği bir halde iken eşini dövmebileceğini düşünmesi gerekmesine rağmen, sarhoş olmuş ve şuurunu yitirdiği anda eşini dövmüştür. Bu durumda kişinin eşine karşı işlemiş bulunduğu yaralama, taksirli bir fiildir.

Bu örnek şu şekilde de formüle edilebilir: Eşiyle arasında tartışma geçen kişi, şuurunu yitirmiş olduğu vaziyette karısını dövmek amacıyla (*doğrudan kast*) veya şuurunu yitirmiş olduğu vaziyette karısını dövmebileceğini düşünerek (*olası kast*) alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde alır ve algılama yeteneğinin yitirilmiş olduğu vaziyette iken, amaçladığı veya muhtemel addettiği şekilde eşinin vücut dokunulmazlığını ihlâl eder.

Belli bir suçu işlemeye karar vermiş olan şahıs, bu suçu işlemek hususunda cesaret kazanmak, suç işlemekten kendini alıkoyan iç dürtülerin (sevki tabiiilerin) etkisinden kurtulmak gibi bir amaçla alkol veya uyuşturucu madde alabilir. Bu durumda, işlediği suça ilişkin olarak kişinin kusur yeteneği var kabul edilecektir.

2) İstemeyerek Sarhoşluk

Kişi, alkol veya uyuşturucu madde almak kastıyla hareket etmemesine rağmen, yanılarak bu maddeleri almış olabilir. Keza, kişi alkol veya uyuşturucu madde almaya mecbur edilmiş olabilir. Gerek bilmeyerek gerek zorla alınan alkol veya uyuşturucu maddenin etkisiyle sarhoş⁷⁸¹ olan kişi, bu vaziyette iken suç teşkil eden bir fiili işlemiş olabilir.

Dikkat edilmelidir ki, bu gibi hallerde, kusur yeteneğinin ortadan kalkması veya azalması dolayısıyla faili muaheze edememekteyiz. Bir başka ifadeyle, bir arızî sebep olarak istemeyerek alkol veya uyuşturucu madde alınması dolayısıyla failin taksirinin dahi olmaması gerekir. Aksi takdirde meseleyi istemeyerek sarhoşluk olarak değerlendirmek mümkün değildir⁷⁸².

Ancak, bu durumda almış olduğu alkol veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalarak işlediği suç dolayısıyla failin cezaî sorumluluğu şu şekilde belirlenmek gerekir: Aldığı alkol veya uyuşturucu madde algılama veya irade yeteneğini tamamen ortadan kaldırmış ya da irade yeteneğini önemli derecede azaltmış ise, failin kusur yeteneği artık mevcut değildir ve kendisine hiç ceza verilmeyecektir (m. 34, f. 1)⁷⁸³. Buna karşılık, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle failin kusur

⁷⁸¹ İşaret etmemiz gerekir ki; alkol ve sair uyuşturucu maddelerin insanın algılama yeteneği üzerinde meydana getirdiği etkide (sarhoşluk) nitelik farkı bulunmamaktadır. ÜNVER, Akıl Hastalığı, sh. 145.

⁷⁸² DÖNMEZER/ERMAN II, no. 897.

⁷⁸³ Ancak, belirtelim ki, 765 sayılı mülga TCK'nın 46. maddesine atıfta bulunulması dolayısıyla faille hiç ceza verilmeyecek ise de; bu maddede "tam akıl hastası" olan kişiler için öngörülen tedbirler fail hakkında uygulanmayacaktır.

yeteneğinde önemli sayılmayacak ölçüde azalma meydana gelmiş ise, bu durum sadece 61. maddenin birinci fıkrası hükmüne göre temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilecektir.

3) İsteyerek Sarhoşluk

İsteyerek alkol veya uyuşturucu madde alınması halinde çeşitli ihtimaller düşünülebilir.

Birinci ihtimalde, kişi belli bir suçu işlemek hususunda cesaret kazanmak için alkol veya uyuşturucu madde almış olabilir.

İkinci ihtimalde, kişi, herhangi bir suç işlemeyi kastetmediği halde, alkol veya uyuşturucu maddeyi almayı istemiştir. Aldığı alkol veya uyuşturucu maddenin etkisinde iken kişi herhangi bir suçu işlemiş olabilir.

Üçüncü ihtimalde ise, kişi alkol veya uyuşturucu madde almak kastıyla hareket etmemiştir. Ancak, gerekli dikkat ve özeni göstermediği için, şuurunu etkileyecek nitelikte olan maddeyi yanlışlıkla almıştır.

İlk iki ihtimalde “ihtiyarî sarhoşluk” hali mevcuttur. 34. maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre, bu durumda kişiyi işlemiş bulunduğu suçtan dolayı tam sorumlu tutmak gerekecektir. Buna göre, her iki ihtimalde de alkol veya uyuşturucu maddenin etkisinde suç işleyen kişinin işlemiş bulunduğu suç açısından kasten mi yoksa taksirle mi hareket ettiğini araştırmak gerekecektir. Çünkü, kişinin sarhoş olması, kasten veya taksirle hareket etmesine engel teşkil etmemektedir⁷⁸⁴.

Gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla yanlışlıkla alkol veya uyuşturucu maddenin alınmış olması haline ilişkin üçüncü ihtimalde ise, sarhoşluk taksirle gerçekleşmiştir. Bu durumda kişinin işlediği suç, taksirle işlenmiş bir suçtur ve ancak bu nedenle cezaî sorumluluğu cihetine gidilebilir⁷⁸⁵.

⁷⁸⁴ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 902; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 287.

⁷⁸⁵ ÖZTÜRK, Ceza hukuku(3), sh. 203.

«İsnad yeteneğini etkileyen sebepler arasında *sarhoşluk* hali de incelenmektedir.

Sarhoşluk konusunda çeşitli kanunların kabul ettikleri sistemler iki ana grupta toplanmakta, bunlardan birinci gruba dahil olanlar, sarhoşluk halinden hiç bahsetmemekte, konuyu genel hükümlere bırakmakta; ikinci grubu oluşturan kanunlar, -kanunumuz bu gruba girmektedir-bazı düzenlemeler getirmektedir.

Kanunumuz bu konuda kaynak kanundan ayrılarak ve daha çok 1931 İtalyan Ceza Kanunu sistemine yaklaşarak 48. maddesinin 2. fıkrasında “*ih̄tiyari sarhoşlukla veya ih̄tiyari ile kullanılan uyuşturucu madde tesiriyle işlenen fiiller bu madde (48/1. m.) hükmünden hariçtir*” hükmünü koymuştur. Bu hüküm karşısında; sarhoşluk, sebebine göre, 1- arızî veya istemeyerek sarhoşluk, 2- ihtiyarî yahut isteyerek sarhoşluk olmak üzere, ikiye ayrılmıştır.

İhtiyarî veya isteyerek sarhoşluk ya da uyuşturucu madde kullanma, çeşitli şekillerde olabilir.

Bunlardan birincisi, *kasden sarhoşluk* (veya uyuşturucu madde kullanma) halidir ki; fail hem alkollü içkiyi (veya uyuşturucu maddeyi) kullanmayı, hem de bunun sonucunda sarhoş olmayı ister. Bir başka ifade ile; failin iradesi hem sebebi (içki içmek), hem de neticeyi (sarhoş olmak) kapsar.

İkinci çeşit isteyerek sarhoşluk ise; *taksirli sarhoşluktur*. Bu halde fail içki içmeyi (veya uyuşturucu madde kullanmayı) ister, ancak bünyesinin dayanabileceğini düşünerek bunun sonucunda sarhoş olmayı istemez. İrade, sebebe ilişkin olmakla beraber, sonucu kapsamına almamaktadır.

Üçüncü bir sarhoşluk ise; *tasarlanmış sarhoşluk* olarak ifade olunmaktadır. Bu tür sarhoşlukta fail, sarhoş olmadan önce belirli bir suçu işlemeye karar verip suçu daha rahatça işlemek için ya da kendisine özür sağlamak amacıyla sarhoş olur ve kararlaştırdığı suçu işler.

Tasarlanmış sarhoşlukta *actiones liberae in causa* (sebebinde serbest olan hareketler) hükümleri uygulanacağından, bu konuda bir uyuşmazlık çıkmamakta(; ancak), isteyerek sarhoşluğun diğer iki halinde isnad yeteneğinin ne suretle ve hangi sebebe dayanılarak kabul edileceği öğretide fikir ayrılıklarına yol açmaktadır.

Kanunumuz *anlayabilme ve isteyebilme yeteneği* olarak yukarıda açıklanan bir hukuki esası benimsemiş ve isnad yeteneği de bu temele dayandırmıştır. Şu halde 48. maddenin son fıkrasını, irade serbestliğine ve ahlâki -manevî- sorumluluk prensibine getirilen bir istisna olarak değil, isnad yeteneği hakkında kanunî görüşün uygulama şekli olarak anlamak lazımdır.

İsteyerek sarhoş olan kimsenin niçin cezalandırıldığı, bu suretle açıklanmakta; ancak, hangi sıfatla cezalandırılacağı hususunda farklı teoriler ileri sürülmektedir. Manevî unsur, sadece isnat yeteneği değil, kusurluluğu da kapsamına almaktadır. Oysa 48. maddenin 2. fıkrası, isnad yeteneği problemini çözümlenmekte, kusurluluk konusunda bir hüküm getirmemektedir. Böyle olunca; isteyerek sarhoş olanın kusurluluk derecesini araştırmak; kasıtlı mı, taksirle mi, hatta kastın aşılması haliyle mi hareket eylediğine bakmak ve ona göre sorumluluğunu belirlemek gerekir. 48. maddenin 2. fıkrası böyle bir yorumu engeller hüküm ihtiva etmemektedir. ... Görülüyor ki; failin kasten veya taksirle cezalandırılması için sarhoşluğun kasıtlı veya taksirli olup olmadığı araştırılmalıdır.

Gerçekten sarhoş olmayıp da isnad yeteneğini tam olarak haiz olan kişinin kusurluluğu araştırılıp sorumluluğu kastına veya taksirine yahut kastının aşılmasına dayandırıldığı halde; kanunen isnad yeteneğinde bir değişme olmadığı da açıklanan sarhoşluk hakkında aynı araştırmanın yapılmaması ve kendisinin daima kasıtlı yahut daima taksirle hareket etmiş sayılması mantıksız olur. Bundan başka kusurluluk hakkında bu araştırma yapılacaksa, bunu hareketle ilgisi olmayan bir zamana, yani sarhoşluğun sebebine götürmek de doğru değildir. Araştırılması gereken, inceleme konusu yapılacak olan, hareketin hangi kusurluluk şekli altında işlendiğini tesbit etmekten ibaretir ve hareketin dışında kalan sarhoşluğun kasıtlı veya taksirli olması ile bu kısım arasında bağlantı yoktur. 48. maddenin 2. fıkrası, isnad yeteneği problemini bu suretle hallet(tiğine ve) kusurluluk sorunu ile uğraşmadığına göre; bunun genel hükümlere göre tesbitini yapmak, kanuna aykırı olmak şöyle dursun, uygun olur ve bu şekildeki yorumla kanun ihlâl edilmemiş olur.

İsteyerek tam sarhoşluk hali hakkında belirlenen bu görüş isteyerek kısmi sarhoşluk halinde de aynen geçerlidir.

Özetlemek gerekirse, ihtiyarî -isteyerek- sarhoşluk sözkonusu olduğunda, sarhoşluğun yoğunluğu önemli değildir ve herhalde isnad yeteneği tam olarak vardır. Ancak, kusurluluk derecesi değişebilir. Meselâ sarhoş olan bir kimse kavgaya tutuşup da hasmını öldürmek istediği zaman, kastla; sadece yaralamak istediği zaman, ölüm meydana gelmişse, kastın aşılmasıyla; sarhoşken araç kullanıp taksirle birini öldürdüğü zaman, taksirle hareket etmiş sayılır ve ona göre cezalandırılır.

Tüm bu açıklamalar gözönünde tutulup; fazla miktarda alkol almış bir halde müştekinin dükkanına giren sanığın, müştekiden sigara alıp bunu müştekiye yaktırdığında çakmağı beğenip pazarlık yaparak 1.000 liraya satın aldığı, ancak sarhoşluğun etkisiyle dükkânı terketmeyip orada bulunanlarla kavgaya girmesi üzerine, olay yerinden geçen bekçilerin sanığı alıp karakola götürdükleri, üzerinin aranmasında suça konu çakmağın çıktığı anlaşılmaya ve olayın baştan itibaren cereyan eden durumuna göre kaç çakmak satın aldığını farkedemeyecek derecede sarhoş olan sanığın, meydana gelen kargaşaya ya da bekçilerin olay yerine gelişinde, satın aldığı çakmağı cebine koymuş olduğunu unutarak ve yanılarak ikinci çakmağı alması mümkün bu-

4) Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Kusur Yeteneği Sorunu

Alkol veya uyuşturucu maddelerin devamlı kullanılması halinde; bu maddeler, kişinin akıl ve ruh sağlığı üzerinde tahribatlar meydana getirmekte ve kişinin kusur yeteneğini etkilemektedir.

Alkol kullanımını itiyad haline getirmiş olan kişi, bu maddeyi kullanma hususunda aşırı bir istek duyar. Ancak, bu bağımlılık fiziksel bir bağımlılık değil, psikolojik bir bağımlılıktır. Bu nedenle, alkol almaktan yoksun bırakıldığında kişide yoksunluk sendromları görülmez⁷⁸⁶. Ancak, kişi alkol kullanma hususunda kuvvetli bir istek duysa bile, bu husustaki iradesinin olmadığını söylemek mümkün değildir. Bu durumda, zayıf da olsa, irade vardır.

Buna karşılık, kronik alkol veya uyuşturucu madde zehirlenmesi ise, bir tür akıl hastalığı gibidir. Maddenin kullanımına ara verildiğinde yoksunluk sendromları görülür. Alkol veya uyuşturucu madde zehirlenmesine maruz kalan kişiler hallüsinasyonlar görmektedirler⁷⁸⁷. Bu kişilerin suç işlemesi halinde, kanımızca akıl hastalarına ilişkin sorumluluk rejimi esas alınmalıdır⁷⁸⁸.

5) “Geçici Neden” Kavramı ve Lohusalık Dönemindeki Annenin Yeni Doğan Çocuğunu Yaralaması Veya Öldürmesi Dolayısıyla Ceza Hukuku Sorumluluğu

“Geçici neden”, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olmaktan ibaret değildir. Örneğin lohusalık döneminde işlenen belirli suçlar bakımından lohusalık hali, bir geçici neden olarak değerlendirilebilir.

Hatta, örneğin evde ütü yapmakla meşgul olan annenin, sokaktan gelen acı fren sesi ve çocuğunun “anne” diye feryadı karşısında, paniğe kapılarak, ütünün fişini çekmeden dışarı çıkması ve yanık vaziyette bıraktığı ütüden kaynaklı yangın çıkması halinde, **genel güvenliği taksirle tehlikeye sokma** suçu bakımından geçici nedene dayalı olarak kusurunun bulunmadığı yönünde değerlendirme yapılabilir. Zira, söz konusu panik halinde annenin davranışlarını hukukun icaplarına göre, objektif özen yükümlülüğünün gereklerine uygun olarak yönlendirme yeteneğinin ortadan kalktığını veya önemli ölçüde azalmış olduğunu söyleyebiliriz.

bulduğuna, mağdurun başlangıçta bu suçtan herhangi bir şikayeti olmadığına, çakmağı çalma durumu mevcut olsaydı aramanın yapıldığı karakola kadar aradan geçen zaman zarfında onu atması mümkün bulunduğuna, müştekinin duruşmada sanığın hırsızlık suçunu işlemiş olacağına ihtimal veremeyeceği hususundaki açıklamasına, sabıkasız olup, iş-güç sahibi olan sanığın satın aldığı bir çakmak mevcut iken, ikincisini çalmasını gerektirir bir sebep ya da amaç olmayacağına göre, *sanıkta hırsızlık suçunun kastı oluşmamıştır*»: CGK., 24.10.1983, 6-215/358 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 606 vd.).

⁷⁸⁶ ÜNVER, Akıl Hastalığı, sh. 146.

⁷⁸⁷ ÜNVER, Akıl Hastalığı, sh. 147.

⁷⁸⁸ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 229; ÜNVER, Akıl Hastalığı, sh. 149/150.

Gebelik dönemi, kadın için başta depresyon olmak üzere çeşitli ruhsal bozukluklara sebebiyet veren riskli bir dönemdir. Doğum sonrası (postpartum) dönemde bu riskin daha da arttığı gözlemlenmiştir⁷⁸⁹. Doğum sonrası dönemde, lohusalık döneminde kadında görülebilen depresyon (postpartum depresyon) ve hatta, psikoz (postpartum psikoz) durumu, özellikle yeni doğan açısından hayati tehlike taşıyan ciddi bir hastalıktır. Bu dönemde anne, intihar girişiminde bulunabileceği gibi, bebeğe zarar verebilir ve hatta onu öldürebilir⁷⁹⁰. Bu itibarla, lohusalık dönemindeki annenin bebeğini yaralaması veya öldürmesi durumlarında lohusalığın kadının işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneği üzerindeki etkilerinin bilimsel bir raporla tespit edilmesi gerekir.

TCK, m. 34 hükümlerinin lohusalık dönemindeki annenin bebeğini yaralaması veya öldürmesi durumlarında dikkate alınması gerektiğini önemle belirtmeliyiz⁷⁹¹.

⁷⁸⁹ HACIOĞLU, Turgut: *Gebelik Dönemindeki Kadınların Yansıtıcı İşlevsel Becerilerinin ve Bağlanma Paterninin Postpartum Depresyon ve Anne Bebek Etkileşimi ile İlişkisi*, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, 2023, sh. 11; ALP, Ahmet: *Postpartum Depresyonu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması*, TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2023, sh. 14 vd.; DUMAN, Rukiye: *Postpartum Depresyon ile Emzirme Özyeterliliği İlişkisinde Annelerin Bebek Bakımına Yönelik Obsesif ve Kompulsif Davranışlarının Aracı Rolü*, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ebelik Yüksek Lisans Tezi, 2023, sh. 5 vd.; ÖZHÜNER, Yase-min: *Postpartum Depresyonun Önlenmesinde Watson Modeline Dayalı Psikoeğitim Müdahalesinin Etkisi*, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2023, s. 10 vd.

⁷⁹⁰ AVCI, Mustafa/YERDELEN, Erdal: *Karar İncelemesi-Garantörsel İhmali Suçta İhmali ve İcra Davranış Ayrımı*, in: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XIX, sayı 1, yıl 2015, sh. 182; YERDELEN, Erdal: *Kusurluluğu Etkileyen Bir Neden: Lohusalık Sendromu (Bir Anne Bebeğini Niçin Öldürür? Canı mı Yoksa Zavallı mı?)*, in: Ceza Hukuku Dergisi, sayı 36, yıl 2018, sh. 9 vd.; YAĞCI Çetin Fatmanur: *Türk Ceza Hukukunda Akıl Hatalığı*, Ankara, 2022, sh. 68.

⁷⁹¹ TCK, m. 35 gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Kişi, gerçekleştirdiği davranışın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğini etkileyen bir nedenin etkisine bilinci olmaksızın veya iradesi dışında girmiş olabilir. Örneğin, kimyasal madde üretiminin yapıldığı bir tesiste çalışan kişiler, kimyasal maddelerden yayılan kokunun etkisinde kalarak, geçici bir süre algılama ve irade yeteneğini tümüyle yitirmiş olabilir. Bu gibi durumda, kusur yeteneğinin olduğundan söz edilemez. Yine yatağında bebeğini emzirdiği sırada uykuya dalan anne, uykudayken bebeğin havasızlıktan dolayı ölümüne neden olabilir. Bu durumda ölüm olayının gerçekleştiği anda anneye ilave edilecek bir fiil bulunmamaktadır. Yani, uyku hâlinde iken kişi hareket yeteneğini yitirmektedir. Ancak, annenin bu ölüm neticesinden dolayı sorumluluğunu belirlerken, uyku hâlindeki davranışlarını değil, uykuya geçmeden önceki dönemde gerçekleştirdiği davranışları göz önünde bulundurmamak gerekir. Anne, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, emzirmek üzere bebeğini yatağına almış ve bu esnada uyuya kalmıştır. Aynı şekilde, hipnotik telkin altına girmiş olan kişinin de bu hâldeyken hareket yeteneğinin varlığından söz edilemez.

Bu bağlamda sorun, TCK, m. 34 düzenlemesinin geçici nedenlerin söz konusu olduğu durumlarda bu nedenin etkisi altında suç işleyen kişiye hiç ceza verilmemesini amir olmasıdır.

Oysa, geçici neden etkisiyle failin özellikle davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğinin azalması durumlarında, cezada indirim yapma hususunda hâkime takdir yetkisinin tanınması, uygulama bakımından daha doğru olurdu⁷⁹².

Yeni TCK’de, mülga 765 sayılı TCK’de (m. 453) mevcut olan, “henüz yeni doğmuş çocuğu öldürme” adıyla bir suç tanımına yer verilmemiştir. Dikkat edilmelidir ki, mülga 765 sayılı TCK’deki düzenleme, evlilik dışı cinsel ilişkiden meydana gelmiş yeni doğan çocuğun öldürülmesi durumuna özgü bir düzenleme idi⁷⁹³. Keza, bu düzenleme, lohusalık evresindeki kadının psikiyatrik durumunu dikkate almamıştı.

Bu düşüncelerle TCK, m.34’e aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra hükmü eklenmesini önermekteyiz:

“(3) Lohusalık dönemindeki annenin bu dönemin etkisi altında yeni doğan çocuğunu yaralaması veya öldürmesi halinde, verilecek cezada üçte birine kadar indirim yapılır. Ancak verilecek sonuç ceza, çocuğun öldürülmesi halinde on yıldan, yaralanması halinde, dört yıldan fazla olamaz.”

Kişi, alkol veya uyuşturucu madde almak kastıyla hareket etmemesine rağmen, yanlışlıkla bu maddeleri almış olabileceği gibi, alkol veya uyuşturucu madde almaya zorlanmış da olabilir. Gerek bilmeyerek gerek zorla alınan alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken işlenen suç açısından kişinin kusur yeteneği bulunmamaktadır. Ancak, belirtmek gerekir ki, geçici bir neden olarak istemeyerek alkol veya uyuşturucu madde alınması dolayısıyla failin taksirinin dahi olmaması gerekir. Kişinin algılama yeteneğini etkileyen sistemik hastalıkları da geçici neden olarak kabul etmek gerekir. Örneğin diyabet, gebelik sonrası ortaya çıkan psikozlar ve üremi gibi hastalıklar, kişinin algılama yeteneğini ortadan kaldırabilmektedir.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 440.

⁷⁹² YERDELEN, Ceza Hukuku Dergisi, 36, 2018, sh. 34 vd.

⁷⁹³ Söz konusu madde düzenlemesi, ilk halinde şu şekilde idi:

*“Kasten katil cürmü, failin veya karısının veya anasının veya kızının ve torununun veya evlatlık kızının veya kız kardeşinin **namusunu kurtarmak için** veledizine aleyhine nüfus siciline kaydından evvel ve doğmasından beş gün zarfında işlenmiş ise, fail beş seneden on seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır.”*

Söz konusu madde, 1933 yılında değiştirilerek, şu şekli almıştı:

*“Kasten katil cürmü failin veya karısının yahut anasının veya kızının ve torununun yahut kız evlatlığının veya kız kardeşinin **haysiyet ve namusunu kurtarmak için** yeni doğmuş çocuk aleyhine işlenmiş ise fail beş seneden on seneye kadar ağır hapisle cezalandırılır.”*

Söz konusu madde, 1991 yılında tekrar değiştirilerek, nihayet şu şekli almıştı:

*“Öldürme fiili, anası tarafından **şerefini kurtarmak saikiyle** yeni doğmuş bulunan çocuğa karşı işlenmiş ise faile dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.”*

Eskurs 7. Zorunluluk Haline İlişkin Kur'an Hükümlerinin Günümüz Hukuk Anlayışına Aktarılması Sorunu

I. Zorunluluk hali, kişiden hukuka uygun davranmasının beklenemeyeceği hali ifade eder.

Kur'an'da zorda kalış durumuna ilişkin hükümlerin başında, yenmesi yasaklanmış olan şeylere ilişkin hükümler gelmektedir⁷⁹⁴. Keza, Kur'an'a göre, baskıya maruz kalmanın etkisiyle gerçeği söylememek, sorumluluğu gerektirmemektedir⁷⁹⁵.

Bu hükümlerden hareketle, kişinin hayatını kaybetmesine veya vücudunun yaralanmasına yönelik somut bir tehlikeyle karşı karşıya kalması, bir yakınının hayatına, vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına saldırı tehdidi altında bulunması, yangın veya doğal bir afet sebebiyle malvarlığının somut bir zarar tehlikesiyle karşı karşıya kalması gibi zorunluluk hallerine ilişkin genel kuralları tespit etmenin mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

II. Zorunluluk halinin varlığı için belirli bir konu bakımından somut bir tehlikenin ortaya çıkmış ve el an mevcut olması gerekir. Bu tehlike, doğal bir olaydan kaynaklanabileceği gibi, bir başkasının tehdidinden ve keza, kişinin kendi sebebiyet verdiği dikkatsiz ve özensiz davranıştan kaynaklanabilir.

Zorunluluk halinden bahsedebilmek için, kişi işlediği fiilin bir haksızlık oluşturduğunun idrakinde olmakla birlikte, bu fiilin icrasında aşırıya kaçmayacak, sınırı aşmayacaktır ("ğayre bâğîn ve lâ 'âdin")⁷⁹⁶. Zorunluluk halinde kişi işlediği fiil dolayısıyla ceza hukuku bakımından sorumlu tutulmaz⁷⁹⁷. Bu itibarla, zorunluluk hali, bir hukuka uygunluk sebebi değil, bir **mazeret sebebidir**. Zira, zorunluluk halinde kişiye "ism" yüklenemeyecektir^{798, 799}. Keza, Kur'an'da zorunluluk hali bağlamında Allah'ın "bağışlayıcı" ("ğafûr") ve "merhamet sahibi" ("rahîm") sıfatlarına işaret edilmiştir⁸⁰⁰.

Zorunluluk halinde sorumsuzluk için, bu tehlikenin bertaraf edilmesine yönelik olarak icra edilen fiille ölçünün çiğnenmemesi, aşırıya kaçılmaması gerekir⁸⁰¹.

⁷⁹⁴ Bakara (2), Ayet 173; Mâide (5), Ayet 3; En'âm (6), Ayet 119, 145; Nahl (16), Ayet 115.

⁷⁹⁵ Nahl (16), Ayet 106.

⁷⁹⁶ Zorda kalan kişi, zorda kalmış anlamında "muztarr" kavramı için bkz. Neml (27), Ayet 62.

⁷⁹⁷ Bakara (2), Ayet 173; En'âm (6), Ayet 145; Nahl (16), Ayet 115.

⁷⁹⁸ Bakara (2), Ayet 173.

⁷⁹⁹ Kişinin içinde bulunduğu şartları ceza hukuku sorumluluğu bakımından dikkate almakla birlikte, zorunluluk halinde, zorda kalan kişinin fiili, bir haksızlık oluşturmaya devam eder ve özel hukuk hükümlerine göre tazminat sorumluluğunu gerektirir.

⁸⁰⁰ Bakara (2), Ayet 173; Mâide (5), Ayet 3; En'âm (6), Ayet 145; Nahl (16), Ayet 115. Ayrıca bkz. Tâhâ (20), Ayet 73

⁸⁰¹ Mâide (5), Ayet 3.

III. Kur'an'daki bu hükümlerde, somut tehlike karşısında, korunan hukukî değerle bu hukukî değerlerin korunması uğruna ihlâl edilen bir diğer hukukî değer arasında birincisi lehine **üstünlük farkı** bulunmaktadır. Bu hükümlerden hareketle, somut tehlike karşısında, korunan hukukî değerle bu hukukî değerlerin korunması uğruna ihlâl edilen bir diğer hukukî değer arasında birincisi lehine üstünlük farkının bulunması halinde, zorunluluk halinin varlığını ve bu sebeple ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidilemeyeceğini kabul etmek gerekmektedir. Örneğin bir kişinin hayatına yönelik somut tehlike karşısında, bu tehlikeden kurtulmak amacıyla ve bu tehlikeyi bertaraf edecek ölçüde bir başkasının mal-varlığına zarar verilmesi durumunda, zorunluluk halinin varlığını kabul etmek gerekecektir.

IV. Maruz kalınan somut tehlike karşısında, korunan ve ihlâl edilen hukukî değerlerin **aynı** olması, bu hukukî değerler arasında fark bulunmaması halinde, zorunluluk hali dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğundan sarfinazar edilip edilemeyeceği, bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin kişinin hayatı bakımından maruz kaldığı somut tehlike karşısında, bu tehlikeyi bertaraf etmek için, bu tehlikenin oluşumunda herhangi bir sorumluluğu olmayan bir kişinin hayatına son vermesi halinde zorunluluk halinin varlığı kabul edilerek ceza hukuku sorumluluğundan sarfinazar edilebilecek midir sorusuna cevap aramak gerekir. Başka bir ifadeyle, maruz kalınan somut tehlike karşısında, korunan ve ihlâl edilen hukukî değerlerin aynı olmasını, bu hukukî değerler arasında fark bulunmamasını, sadece failin cezasında indirim yapma bakımından mı dikkate almak gerekecektir?

Kanaatimizce, maruz kalınan somut tehlike karşısında, korunan ve ihlâl edilen hukukî değerlerin aynı olmasını, zorunluluk hali olarak dikkate almakla beraber, bu durumun ceza hukuku sorumluluğunu büsbütün ortadan kaldıran sebep olarak kabul etmemek gerekir.

V. Yukarıda da belirtildiği gibi, Kur'an'a göre, baskıya maruz kalmanın etkisiyle gerçeği söylememek, sorumluluğu gerektirmemektedir⁸⁰². Ancak bu sorumsuzluk hükmünün, maruz kalınan baskının etkisiyle, suçsuz olan bir insana suç isnadında bulunulması haline teşmil edilebilip edilemeyeceği sorun teşkil etmektedir. Örneğin, mahkemede tanık olarak dinlenen kişi, hayatına yönelik olarak maruz kaldığı tehdidin etkisiyle, gerçeği söylemeyip, suçsuz olduğunu bildiği bir kişiye somut bir suç isnadında bulunursa, hakkında iftira suçu bakımından zorunluluk hali dolayısıyla sorumluluktan sarfinazar edilebilecek midir?

Kanaatimizce, kişinin kendisinin veya bir yakınının hayatına, vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına saldırı tehdidi altında bulunmasını, gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapması bağlamında, zorunluluk hali olarak dikkate almak gerekir. Buna karşılık, kişinin tehdide maruz kalması, tanıklık yaparken bir başkası-

⁸⁰² Nahl (16), Ayet 106.

na suç isnadında bulunmasını mazur addedilmesine ve ceza hukuku sorumluluğunu ortadan kaldıran bir mazeret sebebi olarak kabulüne imkân vermez⁸⁰³.

E. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi

Yeni TCK'nın 28. maddesinde, **kusurluluğu ortadan kaldıran sebeplerden cebir** veya **tehdit** etkisinde kalınarak suç oluşturan bir fiilin işlenmesi halinde, bu fiili işleyen kişiye ceza verilmeyeceği; buna karşılık, cebir kullanan veya tehdit eden kişinin, bu cebir veya tehdit etkisinde bir başkasının işlediği suç nedeniyle **dolaylı fail** olarak sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Aslında böyle bir hükme ceza kanununda yer verilmesinin gereksiz olduğu kanısındayız. Dönmezer Tasarısındaki madde metninde (m. 24) sadece “ikrah” ibaresi “korkutma” olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar madde metninde “cebiri ve şiddet veya ... korkutma veya tehdit” ibareleri kullanılmış ise de, bu madde bağlamında sadece cebir ve tehdit kavramlarına ilişkin açıklamada bulunulacaktır. Zira, şiddet, cebir kavramıyla eş anlamlıdır. “İkrah” karşılığında “korkutma” ibaresine madde metninde ayrıca yer verilmesini doğru bulmamaktayız. Çünkü, korkutma olgusu, tehdidin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bir suçun işlenişi sırasında, kişi, “*mutlak kuvvet*”in (“*vis absoluta*”) kullanılması suretiyle, soyut bir araç durumuna irca edilmiş olabilir. Mutlak kuvvete maruz kalan kişinin işlenen suça ilişkin hiçbir surette iradesinin mevcut olmaması dolayısıyla; bu suç ile kendi arasında bir bağ kurmak mümkün değildir. Bu itibarla, işlenen suçun doğrudan faili, mutlak kuvveti tatbik eden şahıstır.

Cebir (“*zorlayıcı kuvvet*”, “*kompulsiv kuvvet*”, “*vis compulsiva*”), genel anlamı itibarıyla, bir kişiye halen hissedeceği bir kötülük, tecavüz icrası suretiyle, bu veya bir üçüncü kişinin iradesi ve davranışları üzerinde zecrî bir etki meydana getirilmesidir⁸⁰⁴.

Cebre maruz kalan kişi halen icra edilmekte olan bir tecavüzün, kötülüğün kendisinde meydana getirdiği zecrî etkiyle belli bir davranışta bulunmaya motive edilmektedir. Bu tecavüz, kişinin belli bir tehlikeye maruz bırakılması suretiyle de gerçekleştirilebilir. Cebir (zorlayıcı kuvvet) halinde kişi *halen* hissedebileceği bir tecavüzle, kötülükle karşı karşıyadır. Buna karşılık, tehdit halinde, kişi bu tecavüzün, kötülüğün *ileride* meydana geleceği beyanıyla korkutulmaktadır.

Cebir kullanma halinde cebre maruz kalan kişinin iradesi belli bir davranışı, belli bir fiili icra etme doğrultusunda zorlanmıştır. Kişi, cebre maruz kalmasına

⁸⁰³ <https://izzetozgenc.com/makale/zorunluluk-haline-iliskin-kur'an-hukumlerinin-gunumuz-hukuk-anlayisina-aktarilmasi-sorunu> (Yayına giriş tarihi: 15.4.2022; Erişim tarihi: 22.5.2023)

⁸⁰⁴ Cebir kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. CİHAN, Erol: *Cebir Kullanma Cürmü*, 1978, sh. 63 vd.

rağmen, bu fiili işlerken iradesi vardır⁸⁰⁵. Ancak, bu irade, zorlanmış bir iradedir, zor ürünü bir iradedir; yani, hukukun değer attığı bir irade hüviyetini kaybetmiştir. Bu itibarla, cebir tatbiki halinde, kişinin bulunduğu davranış, hukuki anlamda fiil vasfını haizdir. Yani, cebre maruz kalan kişi, işlediği fiil açısından kasten hareket etmektedir⁸⁰⁶. Cebre maruz kalan kişinin, işlediği fiil şayet bir haksızlık teşkil ediyorsa, bu haksızlık dolayısıyla kusurunun mevcudiyetinden bahsedilemeyecektir⁸⁰⁷. Çünkü, maruz kaldığı zorlayıcı kuvvet karşısında mukavemeti, savunma gücü kırılan kişi, belli bir hukuki değere tecavüz teşkil eden haksızlığı -suçu- işlemeye *mecbur* edilmiştir. Bu mecburiyet dolayısıyla kişinin *mazur*, yani *kusursuz* telâkki edilmesi gerekir.

Tehdit halinde, gerçekleşmesi *failin isteğinin yerine getirilmemesi kaydına* bağlı bir tecavüz, kötülük mağdura bildirilmektedir. Tehdidin konusunu, kişinin hayatının veya vücut bütünlüğünün tehlikeye maruz bırakılacağına, suç teşkil eden belli bir fiilin işleneceğinin, genel olarak kuvvet kullanılacağına veya herhangi bir kötülüğün (haksızlığın) gerçekleştirileceğinin beyanı oluşturmaktadır.

Tehdidin mümeyyiz vasfı, tehdidin konusunu teşkil eden tecavüzün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin, failin iradesine bağlı bir husus olduğudur⁸⁰⁸. Tehdit konusu tecavüz, gerçekten veya en azından görünüş itibarıyla failin hakimiyetine bağlılık arz etmektedir. Fakat bu, tehdit konusu tecavüzün mutlaka fail tarafından gerçekleştirileceği anlamına gelmez; failin bir üçüncü kişi vasıtasıyla bu tecavüzü gerçekleştireceğini beyan etmesi de, tehdidin oluşması için yeterlidir.

Cebir veya tehdidin etkisinde işlediği haksızlıktan dolayı kişinin kusursuz addelebilmesi için maruz kaldığı bu *cebiri veya tehdidin* belli bir *ağırlık derecesine* ulaşmış olması gerekir. İşlediği haksızlık dolayısıyla kusurunun mevcut olmadığını kabul edebilmek için, kişinin maruz kaldığı cebir veya tehdidin hangi hukuki değere yönelik olduğunun tayin edilmesi gerekir.

⁸⁰⁵ Kunter'e göre, "eğer fail fizik bir cebir altında hareket etmiş ise, isterse anormal olsun, hareketi ile kendisi arasında ruhî bir bağ olmadığı için hukuken değerlendirilebilen yâni hukuka uygun veya aykırı sayılabilen bir hareket yok demektir" (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 197). Keza *Toroslu*, cebre maruz kalan kişinin davranışının fiil vasfını haiz olmadığı fikrindedir: Cebir kullanılması halinde "failin iradesi tamamen yok olmuştur ve dolayısıyla davranışın ona ait olduğunu söylemek mümkün değildir." (TOROSLU, Ceza Hukuku, sh. 139).

⁸⁰⁶ WELZEL, Lehrbuch, sh. 181; BAUMANN, Jürgen: *Täterschaft und Teilnahme*, in: BAUMANN, Jürgen: Beiträge zur Strafrechtsdogmatik, Bielefeld, 1987, sh. 216/217; BAUMANN/WEBER, sh. 190; MEZGER, Studienbuch, sh. 66; DÖNMEZER/ERMAN II, No. 1037.

⁸⁰⁷ Nitekim BAYRAKTAR, Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, sh. 31. *Toroslu*, ("maddi") cebir halinde failin kusurunun mevcut olmadığını kabul etmekle beraber; bu durumda failin iradesinin mevcudiyetinden bahsedilemeyeceği fikrindedir (TOROSLU, Zaruret, sh. 91).

⁸⁰⁸ Aynı mealde bkz. CGK., 5.4.1993, 4-348/70 (YKD, Eylül 1993, 1398 vd. [1400/1401]); CGK., 3.5.1993, 4-102/129 (YKD, Ağustos 1993, 1232 vd. [1234]). Ayrıca bkz. CGK., 5.4.1993, 4-95/72 (YKD, Mayıs 1993, sh. 767 vd.).

Kanaatimizce cebir halinde tatbik edilen kuvvet, tehdit halinde gerçekleştirileceği beyan edilen tecavüzün oluşturduğu korku, bu cebir veya tehdide maruz kalan kişiyi kendisinden talep edilen haksız bir davranışı icra etmeye, belli bir tecavüze katlanmaya mecbur edecek boyutta olmalıdır. Cebre veya tehdide maruz kalan kişinin, icraî veya ihmalî davranış açısından irade hürriyetinin bertaraf edilmiş olması gerekir. Bu hususun tesbiti ampirik, tecrübî bir metodla değil; normatif bir metodla, yani değerlendirme metoduyla yapılacaktır. Şöyle ki; mecburiyet halinin mevcudiyeti için cebir veya tehditle tecavüze maruz kalan hukuki değer ile, bu cebir veya tehdidin etkisinde gerçekleştirilen haksızlığın ilişkin olduğu hukuki değer arasında yapılan mukayeseli değerlendirmede tercihin birinci lehine olması gerekir: *Hukuki değerler arasında değerlendirilmeye dayalı mukayese prensibi*⁸⁰⁹. Meselâ öldürüleceği beyanının kendisinde oluşturduğu korkuyla kasadaki paraları başkasına veren veya paraların kasadan alınmasına göz yuman banka veznedarı, aslında bir irade açıklamasında bulunmuştur. Ancak, bu irade açıklaması, zora dayandığı için, mecburiyet halinde beyan edilmiş olduğu için, hukukun muteber, hukukun değer attettiği bir irade açıklaması olarak mütalâa edilemez. Çünkü, bir hukuki değer olan malvarlığının korunması karşısında kişinin hayat hakkı önceliği haizdir. Böyle bir durumda; yani, hayat hakkının tercih edilmesi dolayısıyla, belli bir eşyaya ilişkin muhafaza ve nezaret yükümlülüğünden fedakarlık edilmesi durumunda; mecburiyet halinin varlığını kabul etmek gerekir⁸¹⁰.

Tehdit halinde de kişi, tehdit konusu tecavüzün ileride vuku bulacağı beyanıyla korkutularak, belli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır, *mecbur* edilmektedir. Cebirden farklı olarak, tehdit halinde kişi üzerinde fizikî, maddi bir tesir icra edilmektedir. Mağdur bir tecavüzün gerçekleştirileceği beyanıyla korkutulmakta ve bu suretle belli bir davranışta bulunmaya mecbur kılınmaktadır. Bu itibarla, Türk hukukunda, İtalyan doktrininin tesiriyle, tehdit halinde “*manevi cebir*”den bahsedilmesi, tehdidin kişinin irade hürriyeti üzerindeki etkisi açısından, doğrudur. Kişi, tehdit tatbiki suretiyle, sahip olduğu belli hukuki değerlerin tecavüze uğrayacağı beyanının kendisinde oluşturduğu korkuyla, mukavemeti, savunma gücü kırılmaktadır. Tehdide maruz kalan kişinin işlediği fiil şayet bir haksızlık teşkil ediyorsa, gerçekleştirilen bu haksızlık nedeniyle kişinin kusurunun mevcudiyetinden bahsedilemez. Korkunun oluşturduğu mecburiyet dolayısıyla, kişi *mazur*, *kusursuz* telâkki edilmelidir⁸¹¹.

F. Zorunluluk Hali Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi

Yeni TCK’nın 25. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen **zorunluluk hali**, kusurluluğu etkileyen bir **mazeret sebebidir**⁸¹².

⁸⁰⁹ YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 263.

⁸¹⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN, *Uygulamalı Ceza Hukuku*, sh. 267 vd..

⁸¹¹ YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 298, 308.

⁸¹² Yeni TCK ve CMK’nın (m. 223) düzenlemelerine rağmen, Türk doktrininde bazı yazarlar kitaplarında zorunluluk halinin bir “hukuka uygunluk nedeni” oluşturduğu yönünde açıklamada bulun-

Bir olayda mazeret sebebinin varlığı halinde; işlenen fiil, haksızlık teşkil etme niteliğini korumaktadır. Buna karşılık, söz konusu haksızlığı gerçekleştiren şahıs, zaruret halinin varlığı dolayısıyla, kusurlu addedilmemektedir⁸¹³. Gerçekleştirdiği fiil, nitelik itibarıyla bir haksızlık teşkil etmesine rağmen; bu fiile ilişkin olarak irade kabiliyetinin ortadan kalkması veya genel olarak etkilenmesi dolayısıyla; faili *mazur* addetmekteyiz; bir başka ifadeyle, muaheze etmemekteyiz⁸¹⁴. Kişiyi kusur isnad edilebilmesi için, kendisinden davranış normlarına

makta ısrar etmektedirler: CENTEL, Fatma Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem: *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, 4. bası, İstanbul, Ekim 2006, sh. 348; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 2. bası, sh.322 vd. Belirtmek gerekir ki, Alman Kanun koyucusu, zorunluluk halinin hukuki niteliğiyle ilgili olarak doktrinde ileri sürülen farklı görüşler karşısında, 1975 yılında CK'da yaptığı düzenleme ile, maslahatçı bir yaklaşımla ve orta bir yol izleyerek zorunluluk halini *hukuka uygunluk sebebi* (Paragraf 34) ve *mazeret sebebi* (Paragraf 35) olarak ayırma tabi tutmuştur. *Özbek*, yeni TCK'da da bu ayırma dayalı bir düzenleme yapılmasının daha doğru olacağını ileri sürmektedir: ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 2. bası, sh.322; MERAKLI, Ceza Hukukunda Kusur, sh. 384 vd.

Kangal da aynı görüşte taraftardır. Zorunluluk halinin hukuka uygunluk nedeni olarak veya mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu olmak üzere ikiye ayıran yazara göre; “*failin korumaya çalıştığı tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal yarar, kurtarma fiili ile ihlal edilen masum üçüncü kişiye ait hukuksal yarardan önemli ölçüde daha üstünse, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun mevcudiyeti kabul edilmelidir.*” (KANGAL, Zorunluluk Durumu, sh. 48; ayrıca bkz. sh. 42, 55).

Yazarın bu açıklamalarında bir çelişki bulunmaktadır. Bir yandan bir fiile ilgili olarak “**hukuka uygun**”luk değerlendirmesinde bulunulmakta ve fakat aynı zamanda bu fiilin “**masum üçüncü kişiye ait hukuksal yararı ihlal**” ettiğinden söz edilmektedir. Belirtmek gerekir ki, bir hukuki değer ihlal edildiği bir durumda, hukuka uygun fiilden söz edilemez. Keza, hukuka uygun bir fiilin varlığı halinde, artık bir hukuki değer (veya “hukuksal yarar”) ihlalden söz edilemez.

Yazarın yaptığı açıklamalarda, hukuki değer ve suçun konusu kavramları ile bu kavramlarla bağlantılı olarak ihlal ve zarar kavramları birbirine karıştırılmıştır. Yazara göre hukuki değerle hukuki yarar birbirinden farklı kavramlardır (KANGAL, Zorunluluk Durumu, sh. 225). Hukuki değer kavramı, bizim açıklamalarımızla örtüşen bir şekilde açıklanmıştır. Buna karşılık, klasik suç teorisinden farklı olarak, hukuksal yarar, bir kişiyle ilişkilendirilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu yönü itibarıyla yazarın yaptığı açıklamalarda “hukuksal yarar” kavramı ile suçun konusu arasındaki anlam farkı ortadan kalkmaktadır. Bu ayırım esas alan yazarın, belirli bir kişinin mağdur edilmediği suçlarla bağlantılı olarak “hukuksal yarar” kavramına ilişkin açıklamalarını merak etmekteyiz.

Yazara göre, kişi eğer hayatını, vücut bütünlüğünü veya **daha değerli bir malvarlığını kurtarma uğruna** hırsızlık yapmış ise, bu hırsızlık suçu bakımından bir **hukuka uygunluk nedeni** olarak zorunluluk hali söz konusudur ve fail hakkında “beraat” kararı verilmelidir (KANGAL, Zorunluluk Durumu, sh. 50/51).

Yazar, zorunluluk haliyle ilgili olarak benimsediği ayırım ölçütünü esas alarak, **cebir veya tehdit etkisi altında kalınarak suç oluşturan bir fiilin işlenmesi halinde**, duruma göre bu fiilin “**hukuka uygun**” olabileceği fikrindedir (KANGAL, Zorunluluk Durumu, sh. 55).

⁸¹³ Nitekim BLEI, Allgemeiner Teil, §60; ROXIN, Bockelmann-F., sh. 288 vd.; aynı yazar, Lehrbuch(1), 19/49; BAUMANN/WEBER/MITSCH, §23, kn. 2. *Schmidhäuser*’in fikrine göre; zaruret halinde işlenen fiillerde kişi hukuken kusurlu addedilmemekle beraber, ahlâken kusurlu telâkki edilebilir (SCHMIDHAEUSER, Lehrbuch, §4, kn. 11, §7, kn. 12, § 8, kn. 4 vd.). Keza, *Schmidhäuser*’e göre, zaruret halinin varlığı halinde kişi hukuken kusurlu addedilemeyeceği gibi, ortada bir suçun varlığından da bahsedilemeyecektir (SCHMIDHAEUSER, Lehrbuch, § 4, kn. 29).

⁸¹⁴ Bu nedenle, hukuka uygunluk sebeplerinin “mazeret sebepleri” olarak tavsifi (EREM, Faruk: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, cilt II, 12. bası, Ankara 1985, sh. 1 vd.; ALACAKAP-TAN, sh. 84), kanaatimizce isabetli değildir.

uygun hareket edebilmesi beklenebilmelidir⁸¹⁵. Eğer kendisinden norma uygun davranması beklenemiyorsa, kişiyi kusurlu addedememekteyiz⁸¹⁶.

Bu nedenle, mazeret sebepleri, kusurluluğu etkileyen nedenlerin bir değişik ifadesi olarak telâkki edilmektedir^{817, 818}.

Erem'in mazeret sebepleri kavramı hakkındaki açıklamaları birbirleriyle tutarlılık arz etmektedir: Kusurluluğu kaldıran sebepler olan mazeret sebeplerinden (EREM, Genel Hükümler II, sh. 1, 3) birinin etkisi altında işlenen fiillerin gerçekte hukuka aykırılık vasfını muhafaza etmekle beraber; bu fiili dolayısıyla fail kusurlu addedilemez. (EREM, Genel Hükümler II, sh. 3). Ancak, bu doğru teşhise rağmen; *Erem*, şu açıklamalarda bulunmaktadır: “Mazeret sebebi ile işlenen fiilin hukuka aykırı olmadığını, ancak failde kusur görülmemesi ile izah edebiliriz. Kusurluluk, hukuka aykırılıktan evveldir” (EREM, Genel Hükümler II, sh. 3). “Mazeret sebepleri, failde kusur görülmediği için, fiilin hukuka aykırılığını kaldırmıştır” (EREM, Genel Hükümler II, sh. 4). *Erem*'in bu son izahlarına iştirak etmemiz mümkün değildir.

⁸¹⁵ Zumutbarkeit.

⁸¹⁶ BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 23, kn. 7; MAURACH/ZIPF I, sh. 432.

⁸¹⁷ Nitekim, *Erem*, mazeret sebeplerini, kusurluluğu ortadan kaldıran sebepler olarak telâkki etmektedir (EREM, Genel Hükümler[8], sh. 24). *Bockelmann/Volk*, kusurluluğu ortadan kaldıran bütün sebepleri, “mazeret sebepleri” başlığı altında tetkike tabi tutmaktadır (BOCKELMANN/ VOLK, Allgemeiner Teil, sh. 197 vd.). Ayrıca bkz. JESCHECK, Ceza Hukuku, sh. 30.

⁸¹⁸ Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 10.5.2016 tarihli ve E. 2013/30385, K. 2016/4656 sayılı Kararı-na konu teşkil eden olayda, sosyal güvencesi bulunmayan ve hamile olan S, doğum sancılarının başlaması üzerine, eltişi E'ye ait sosyal güvenlik sisteminden yararlanma belgelgesi “Yeşil Kart”ı alarak ... Devlet Hastanesi'ne başvurur. E'nin yeşil kartı kullanılarak S'nin hastaneye yatışı sağlanır. S, normal doğum ile bir kız çocuğu dünyaya getirir. Bu doğumla ilgili hastane harcamaları, doğum yapan kişi E imiş gibi bu kişiye ait sosyal güvence çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

İlk Derece Mahkemesi, bu olayda, S ve E'nin beraatine hükmetmiştir.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, aşağıdaki gerekçe ile bu hükmün onanmasına karar vermiştir:

S'nin, E'ye “ait yeşil karttaki fotoğraf ve kimlik bilgileri üzerinde herhangi bir tahrifat yapmadan hastaneye müracaat ederek belgeyi görevlilere ibraz ettiği, muayene için gelen kişilerin ibraz ettiği belgedeki kişi olup olmadığını denetleme görevi bulunan hastane görevlilerinin muayene edilen hastanın kimlik sahibi olmadığını basit bir inceleme sonunda anlayabilecek durumda oldukları, (S ve E'nin) bu durumun denetlenmesi imkanını ortadan kaldırıcı bir davranışlarının bulunmadığı ayrıca hamile olan ve olay günü doğum sancısı başlayan (S'nin), doğmak üzere olan bebeğini muhakkak bir tehlikeden kurtarma zorunluluğunun bulunduğu, hayati önemi haiz nitelikte bir tehlikeden korunmak, bu nedenle doğumunu gerçekleştirmek amacıyla başkasına ait yeşil kartın kullanılması şeklinde gerçekleştirildiği sabit görülen eylemlerin, 5237 sayılı TCK'nın 25/2. maddesinde tanımlanan **zorunluluk hali** kapsamında kaldığı anlaşılmakla; (S ve E) hakkında dolandırıcılık suçunun yasal unsurları itibarıyla oluşmadığı gerekçesiyle verilen beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (Benzer olaylarla ilgili olarak aynı gerekçelerle verilen kararlar için bkz. Yargıtay 15. CD, 26.1.2017, E. 2014/11845, K. 2017/1062; Yargıtay 15. CD, 16.2.2017, E. 2014/11879, K. 2017/6250.).

Hukukî değerlendirmemiz:

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin onama kararından, dolandırıcılık suçunun hile unsuru ile zorunluluk haline ilişkin gerekçelerin birbirine karıştırıldığı anlaşılmaktadır. Bu iki hususun birbirinden ayrı değerlendirmeye tabi tutulması gerekirdi.

Şöyle ki, söz konusu olayda, şahsen katılmamakla birlikte, dolandırıcılık suçunun hile unsurunun oluşmadığı kabul edilebilir. Bu kabule bağlı olarak, dolandırıcılık suçunun oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmesi doğrudur.

Mazeret sebebinin, kusuru ortadan kaldıran diğer sebepler karşısında arzettiği özellik; mazeret sebebinin varlığı halinde, kusurlu addedilmemekle beraber, kişi hakkında herhangi bir tedbir uygulanmasından söz edilemez. Buna karşılık, kusuru ortadan kaldıran diğer sebeplerin varlığı halinde, kusurlu addedilmemesine rağmen, kişi hakkında tedbir uygulanabilmektedir⁸¹⁹.

Zorunluluk hali, klasik suç teorisinin aksine, yeni TCK'nın hazırlanmasında esas alınan suç teorisinde, **kusurluluğu etkileyen bir neden (mazeret sebebi)** olarak telakki edilmiştir. Halbuki, ülkemizdeki ceza hukukçuları arasında yaygın bir şekilde kabul gören klasik suç teorisinde zorunluluk hali bir “hukuka uygunluk nedeni” olarak kabul edilmektedir.

Yeni TCK'nın 25'inci maddesinin ikinci fıkrasının gerekçesinde zorunluluk halinin “*kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak*” telakki edildiği açık bir şekilde vurgulanmıştır. Aynı düşünceyle, yeni CMK'nın 223'üncü maddesinde, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması halinde beraat kararının verilebileceği belirtildikten sonra (f. 2, bent d); “*yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi*” hallerinde, kusurun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilebileceği (f. 3, bent b), hüküm altına alınmıştır. CMK'nın bu düzenlemesi de göz önünde bulundurulduğunda, mevzuatımızca zorunluluk halinin kusurluluğu etkileyen bir neden olarak kabul edildiği açık bir şekilde görülecektir⁸²⁰.

Yeni TCK'ya ilişkin olarak TBMM Adalet Alt Komisyonundaki çalışmalarımız sırasında; akademisyenler olarak, Kanunun Birinci Kitabının İkinci Kısım altında “*Hukuka Uygunluk Nedenleri*” ve “*Kusurluluğu Etkileyen Nedenler*” olarak iki ayrı Bölüme yer verilmesini ve mevcut İkinci Bölüm altındaki maddelerin buna göre yeniden tasnif ve formüle edilmesini önermiştik. Ancak bu yöndeki girişimimizden olumlu sonuç elde edemedik. Düşüncemiz gerçekleşseydi, zorunluluk halini sadece kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak değil, daha genel bir şekilde, kusurluluğu etkileyen bir neden olarak düzenleyecektik. Ancak, bu girişimimizde başarılı olamadığımız için, Kanunun Özel Hükümler Kitabındaki çeşitli suç tanımları bağlamında

Buna karşılık, zorunluluk halinin varlığı kabul edildiği takdirde, suçun oluşmuş olmasına rağmen, zorunluluk hali sebebiyle kişi işlediği suç bağlamında kusurlu addedilemeyeceği için, hakkında beraat kararı değil, **ceza verilmesine yer olmadığı kararı** verilmesi gerekirdi.

Bu karar, Yargıtay Dairesinin zorunluluk haline ilişkin suç teorisi bilgisinden ve hatta, CMK, m. 223, f. 3 hükümlerine ilişkin bilgiden yoksun olduğunu göstermektedir.

⁸¹⁹ BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 23, kn. 14; FRISTER, Helmut: *Die Struktur des “voluntativen Schuldlements”*. *Zugleich eine Analyse des Verhältnisses von Schuld und positiver Generalprävention*, 1993, sh. 245 vd.

⁸²⁰ HAKERİ, Ceza Hukuku, 5. bası, sh. 261; ÖZAYDIN, sh. 238 vd.

ayrıca zorunluluk haline ilişkin hükümlere yer verilmesi gereği ortaya çıkmıştır (m. 92, 147).

Ancak, bu durum, Kanunun sadece sistematigi bakımından bir nakısa oluşturmaktadır; madde içeriklerinin suç genel teorisinin ulaştığı veriler çerçevesinde formülasyonu ve yorumlanması açısından bir sorun ortaya çıkarmamaktadır.

Zorunluluk halinin varlığını kabul için, tehlikeli durumun bir doğa olayından veya bir insan davranışından kaynaklanması arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle, klasik suç teorisinin etkisindeki yazarlarca, bir “hukuka uygunluk nedeni” olarak telakki edilen zorunluluk hali ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerden biri olarak görülen “mücbir sebep” arasında yapılan ayırımın, fiktif bir ayırım olduğu gözden uzak tutulmamalıdır⁸²¹.

Bir tabiat olayı ya da başka insanların kusurlu veya kusursuz davranışlarının sebebiyet verdikleri hadiseler de, muayyen bir fiille alâkalı olarak kişinin irade kabiliyetini etkileyici bir faktör olabilir⁸²².

Meselâ bir sel felaketinin sebebiyet vereceği büyük bir zararı önlemek amacıyla, su yolunu değiştirerek bir başkasının daha az kıymeti haiz malının zarar görmesine sebebiyet veren kişiyi, gerçekleşen mala zarar verme suçundan dolayı kusurlu addetmemekteyiz.

Keza, bir yangın felaketinin yayılmasını önlemek amacıyla, yangının çıktığı binaya veya komşu binalara zarar veren şahsı bu fiilinden dolayı kusurlu addetmemiz söz konusu değildir ve bu nedenle cezaî sorumluluğu cihetine gidilemez⁸²³.

⁸²¹ Buna rağmen, bazı yazarlar yeni TCK’da mücbir sebebe ilişkin bir hükme yer verilmesi gerektiğini savunmaktadırlar (YARSUVAT/BAYRAKTAR ve diğerleri, sh. 295).

⁸²² *Torosluların* zaruret hali ve mücbir sebep kavramlarının birbirinden farklı kavramlar olarak telakki eden şu izahlarına iştirak etmemekteyiz:

“Zaruret halinde bulunan kimse suç işlemeğe mezu kılınmış ise de; icbar edilmiş değildir. Yani kendisini veya üçüncü şahsı feda ederek suçu işlemeyebilir. Fakat mücbir sebep halinde failin başka şekilde hareket etme imkânı yoktur. Bunun neticesi olarak bu iki müessese arasındaki en bariz fark ortaya çıkar: Zaruret halinde fail iradî olarak hareket eder. Esasen iradî hareket, hukuka uygunluk sebeplerinin mümeyyiz vasfıdır. Halbuki mücbir sebep halinde fail, kendisini kanuna uygun hareket etmek imkânsızlığı içinde bulur ve bu da kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep teşkil eder. Zira bu hallerde failin isteme kabiliyeti mevcut değildir ve fail ile fiil arasındaki psikik bağın noksanlığı, fiilin ona isnad edilmesine imkân vermez.” (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 90).

⁸²³ Nitekim Yüce, bu örneklerde zaruret halinin mevcut olduğu gerekçesiyle, faile ceza verilemeyeceği görüşündedir (YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 264). Ancak, Türk Ceza Kanunu’nda sadece “nefs”e karşı vaki tehlikeler karşısında “işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilemez”yeceği öngörüldüğü için (m. 49, fıkra 1, bend 3: zaruret hali); meselâ kıymetli bir mala karşı fiilhal vaki bir tehlikeyi bertaraf etmek için başkasının malına zarar verilmesi halinde bu (49.) madde hükmünden hareketle failin zaruret halinde olduğunu ve dolayısıyla, cezaî sorumluluğunun olmadığını kabul etmek mümkün görülmemiştir (TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 112). Bu durum karşısında; Yargıtay, kıymetli bir mala karşı vaki bir tehlikeyi gidermek amacıyla başka-

Dikkat edilmelidir ki; failin irade kabiliyetinin bu tür olaylarda gerçekten etkileneip etkileneceğini araştırmaya gerek yoktur. Böyle bir durumda bir değerler mukayesesinin yapılması gerekir⁸²⁴. Bu mukayese sonucunda tercih edilen değer şayet feda edilen değere nazaran daha üstün bir değer ise veya en azından eşit düzeyde değerler ise, failin birinci değer korunması hususunda failin iradesinin etkileneip etkileneceğini kabul etmek gerekir. Bu mukayese, normatif bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.

Yukarıda yorum ve kıyas yasağı bağlamında yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz gibi, **TCK'nın zorunluluk haline ilişkin hükümlerinin uygulama alanını mümkün olduğunca geniş tutmak gerekir**^{825,826,827,828,829}.

sının malvarlığına zarar verilmesi halinde failin, “ızzar kastı”nın olmadığından bahisle, nası ızzar suçundan dolayı cezalandırılmayacağı hususunda içtihatla bulunmuştur. Yani, bu gibi durumlarda Yargıtay, failin “özel kast”la hareket etmesini şart olarak aramaktadır:

“Sanığın evini basan sel sularından kurtulmak için, evinin bitişiğindeki bölge yatılı okulunun duvarından zaruret sonucu bir delik açtığı ve sel sularını buradan akıtmak suretiyle muhtemel tehlikeyi önlediği fiilinde ızzar kastı.. bulunma”maktadır: 6. CD., 19.10.1983, 3720/2709 (Çağlayan IV, sh. 666); aynı mealde 6. CD., 1.3.1983, 10436/1592 (Çağlayan IV, sh. 668).

Fakat, dikkat edilmelidir ki; nası ızzar suçunun oluşması için aranan kast, genel kasttır (Nitekim bkz. CGK., 17.12.1984, 9-436/198: Savaş/Mollamahmutoğlu IV, sh. 5413 vd [5415], Çağlayan IV, sh. 648 vd. [650]).

⁸²⁴ YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 263.

⁸²⁵ Bazı suçlarda mağdur da, maruz kaldığı suça ilişkin delilleri yok edebilir. Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarının (TCK, m. 102, 103) mağdurları, bu bağlamda göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu suçların mağduru, suçluyu kayırmak, suç dolayısıyla başlatılan soruşturma ve kovuşturmayı akim kılmak için değil; kendisi bakımından “ayıplı” olmayı sonuçlayan bu durumu örtmek amacıyla, maruz kaldığı fiil nedeniyle yaşadığı “kirlenmişlik” duygusunun etkisiyle, suça ilişkin delilleri yok edebilmektedir. Bu durumda olan bir kişiden, hukukun suç delillerini yok etmeme yönündeki icabına uygun davranması beklenemez. Yani bu bağlamda kişinin irade serbestisinin, davranışlarını serbestçe yönlendirebilme yeteneğinin azaldığını ve hatta bulunmadığını kabul etmemiz gerekir.

Aynı durum, yalan tanıklık ve iftira suçları bakımından da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin genç bir kadın, bir başkasıyla aralarında henüz evlilik birliği oluşmadan cinsel ilişkiye girdikten sonra, içinde bulunduğu aile ve sosyal çevrenin baskısıyla, bu ilişkinin zorla gerçekleştiğinden bahisle suç duyurusunda bulunma gereğini hissedebilmektedir. Tersine bir durum da olabilmektedir. Cinsel saldırı veya cinsel istismar suçuna maruz kalan genç kadın, içinde bulunduğu aile ve sosyal çevrenin yönlendirmesiyle bilahare bu suçun failiyle evlenebilmektedir. Bu kişi hakkında cinsel saldırı veya cinsel istismar suçundan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde mağdur ve tanık sıfatıyla dinlenen kadın, tesis edilmiş olan evlilik birliğinin bekası uğruna gerçeğe aykırı beyanlarda bulunabilmektedir.

Genç kadının fiili birinci ihtimalde iftira suçu, ikinci ihtimalde ise yalan tanıklık suçu bağlamında değerlendirilirken, içinde yaşadığı şartlar itibarıyla hukukun icaplarına uygun davranma yeteneğinin azaldığını ve hatta ortadan kalktığını göz önünde bulundurmak gerekir. Yani bu bağlamda kişinin irade serbestisinin, davranışlarını serbestçe yönlendirebilme yeteneğinin azaldığını ve hatta bulunmadığını kabul etmemiz gerekir.

⁸²⁶ Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.4.2016 tarihli ve E. 2014/9-275, K. 2016/209 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda F, kendisinin darp edildiği ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğu beyanıyla belirli kişiler hakkında suç ihbarında bulunur. Bu kişiler hakkında soruşturma

devam ederken, F, şikayetten vazgeçtiğini beyan eder. Bunun üzerine F hakkında iftira suçundan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıdaki gerekçe ile, bu olayda şikayetinden rücu eden F'nin iftira suçunu işlemediği yönünde içtihatla bulunmuştur:

“Failin sonradan isnadından rücu etmesi, iftira suçunun oluştuğunun kabulü bakımından tek başına yeterli bir kıstas değildir. Zira iftira suçunun faili, ihbarın asılsızlığının anlaşılması veya pişmanlık duyması gibi nedenlerle isnadından rücu edebileceği gibi, isnada maruz kalanın veya yakınlarının kişiyi mahkûmiyetten kurtarmayı hedefleyen baskı ve istekleri sonucu veya temin ya da vaat ettikleri çıkar karşılığında yahut çok başka nedenlerle de isnadından dönmüş olabilir. Bütün bu hallerde belirleyici olan husus, iftira suçu failinin, suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye ihbar veya şikayet suretiyle suç isnat edip etmediğidir.

Bu (itibarla, somut) olayda; sanığın iftira kastıyla hareket ettiğine ilişkin yeterli delilin bulunmadığı, sanığın amacının bir an önce kolluğun müdahale ederek şikayetçi tarafından gerçekleştirilen yaralama eyleminin son bulmasını sağlamak olduğu, şikâyet hakkını kullandığının kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla suçun hukuka aykırılık ögesinin oluşmadığı anlaşıldığından, atılı suçtan (iftira suçundan) sanığın beraatına karar verilmesi gerekmektedir.”

Karara konu teşkil eden olayda işlenmiş olan fiillerden bahisle ihbar ve şikayette bulunmuştur. Ancak bu fiiller sebebiyle ilgililer hakkında soruşturma devam ederken, F, sosyal çevre baskısı veya para vaadi gibi çeşitli mülahazalarla bu şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmiştir. Bu vazgeçme sırasında, genellikle, ihbar ve şikayete konu edilen fiillerin işlenmediği beyan edilmektedir.

Bu gibi rücu olaylarında yapılması gereken, ihbar ve şikayete konu fiilin gerçekte işlenmiş olup olmadığının tespiti. Şayet fiil işlenmiş ise, ihbar ve şikayette bulunmanın bilahare bu ihbar ve şikayetinden vazgeçmesi, iftira suçuna vücut vermez. Bu durumda, ihbar ve şikayetten vazgeçen mağdurun bu tutumunu gerçeğe aykırı tanıklık bağlamında ele alıp değerlendirmek gerekir. Mağdur, tanıklık yaparken, genellikle şikayetinden vazgeçtiğini ve bu çerçevede dolaylı da olsa ihbar ve şikayet konusu fiilin işlenmediğini beyan etmektedir. Bu durumda **yalan tanıklık** suçunun işlendiği konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak, TCK'nın **zorunluluk haline** ilişkin hükümlerini dikkate alarak, bu sorunun, yalan tanıklık yapan **mağdurun kusurluluğu** bağlamında ele alınması gerekmektedir.

Şayet yapılan araştırmada ihbar ve şikayete konu edilen fiil işlenmemiş ve buna rağmen belirli kişilere isnatta bulunulmuş olduğu anlaşılmış ise, bu durumda bilahare bu şikayetten rücu, iftira suçunda etkin pişmanlık (TCK, m. 269) bağlamında ele almak gerekir.

Ancak çoğu zaman, ihbar ve şikayete konu fiilin işlenip işlenmediğinin tespitinde güçlükle karşılaşilmektedir. Bu gibi durumlarda sorunun, in dubio pro reo kuralı gereğince, yalan tanıklık ve bu suçtan dolayı mağdurun kusurluluğu bağlamında ele alınmasının daha doğru bir yöntem olacağını düşünmekteyiz.

⁸²⁷ Yargıtay'ın bir kararına konu teşkil eden olayda; S ve M, karlı bir kış gününde köy yolunda gitmekte iken domuz saldırısına uğrarlar. S, arkadaşı M'yi domuzdan kurtarmak için, tabanca ile ateş eder. Ancak, kurşunlardan biri M'ye isabet ederek ölümüne sebebiyet verir (9. CD, 6.12.1983, 3253/3114).

Bu olayda Esas Mahkemesi, S hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü kurar. Buna karşılık Daire, söz konusu olayda zorunluluk haline ilişkin hükümlerin uygulanması ve S hakkında ceza verilmemesi gerektiği gerekçesiyle bu kararı bozar.

Hayvan saldırısına maruz kalma halinde, kişinin hayatına veya vücut bütünlüğüne yönelik el an gerçekleşmekte olan bir **tehlike** mevcuttur. Bu tehlikeden kurtulmak için tehlikenin kaynağını oluşturan hayvan öldürüldüğünde, şayet bu hayvan sahipli ise, işlenen **mala zarar verme suçu** bakımından **zorunluluk haline** ilişkin hükümleri (TCK, m. 25, f. 2; CMK, m. 223, f. 3, bent b) uygulamak gerekir.

Öldürülen hayvanın sahipli olmaması durumunda, suç oluşturan bir haksızlıktan söz edilemez. Ancak olayda sorun, tehlike kaynağını oluşturma sebebiyle sahipsiz olan hayvanın öldürülmesi ile ilgili değildir. Olayda S, arkadaşı M'yi maruz kaldığı yabani hayvan saldırısından kurtarmak

için silahıyla ateş eder. Ancak, S, bu tehlikeden kurtarmak için tehlikenin kaynağını oluşturan hayvanı öldürmek isterken, olayın meydana getirdiği korkuyla, telaşla, heyecanla, M'yi vurur.

Zorunluluk halinden söz edebilmek için suç oluşturan fiilin mutlaka tehlike kaynağına yönelik olarak işlenmesi gerekmektedir. Bir hayvan saldırısına maruz kalan kişi, bu saldırıdan kurtulmak için, bir başkasına ait eve sahibinin rızasını almaksızın girmesi halinde, konutun sahibine karşı **konut dokunulmazlığının ihlali suçunu** işlemiş olmaktadır. Ancak, bu suçun işlenmesi bakımından **zorunluluk haline** ilişkin hükümleri uygulamak gerekir.

Karara konu teşkil eden olayda S, M'ye karşı, taksirle öldürme (TCK, m. 85, f. 1) suçunu işlemiştir. Ancak, S, maruz kaldıkları domuz saldırısı karşısında, saldırıdan kurtulmak için silahla ve domuzu hedef alarak ateş etmiş ise de, olayın meydana getirdiği korku, telaş ve heyecanla arkadaşı M'yi vurmuş ve ölümüne sebebiyet vermiştir.

Bu gibi durumlarda kişinin hukukun icaplarına göre hareket etme bakımından davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azaldığını ve hatta ortadan kalktığını ve dolayısıyla, işlediği suçtan dolayı kusurunun bulunmadığını kabul etmek gerekir.

TCK'nın 27. maddesinin ikinci fıkrasında, sadece meşru müdafaa sınıрын korku, telaş veya heyecan dolayısıyla aşılması hali kusurluluğu kaldıran bir sebep olarak düzenlenmektedir. Meşru müdafaa'nın varlığı halinde fail hakkında beraat kararı (CMK, m. 223, f. 2); buna karşılık sınıрын korku, telaş veya heyecan sebebiyle aşılması halinde ise, fail hakkında kusurunun bulunmaması sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığı kararı (CMK, m. 223, f. 3) verilmektedir. TCK'nın 27. maddesinin ikinci fıkrası, bu ayırıma işaret etmek için Kanuna dercedilmiş olan bir hükmüdür. Olayımızdaki durumlarda ise, söz konusu hükmün uygulanabilirliği bulunmamaktadır. Ancak bu gibi durumlarda, genel olarak zorunluluk haline ilişkin hükümleri (TCK, m. 25, f. 2) uygulamamız gerekir.

Bu gerekçelerle, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bozma kararını sonuç itibarıyla doğru bulmaktayız.

828

Zorunluluk halinin özellikle bir "hukuka uygunluk sebebi" mi yoksa **kusurluluğu etkileyen bir sebep** mi olduğu konusundaki doktriner tartışmaların aksine, ceza hukuku mevzuatımızda yer alan bu konudaki hükümlerin değerlendirmesine ve uygulanmasına ilişkin içtihatlarla pek nadir rastlanmaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına konu teşkil eden ve zorunluluk haline ilişkin hükümlerin uygulanması bakımından önem arz ettiğini düşündüğümüz iki olay, aşağıda özetlenerek değerlendirilmiştir:

I. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12.3.2019 tarihli ve E. 2018/437, K. 2019/203 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; ... İli ... İlçesi ... Köyünde ikamet eden S, evine gelen **terör örgütü mensubu silahlı iki kişinin** kendisinden gübre ve yiyecek istemesi üzerine önce bu talebi reddeder. Ancak bu kişilerin kendisini **tehdit** etmesi üzerine yardımda bulunmayı kabul eder ve örgüt mensuplarınca verilen para karşılığında kendisinden istenen malzemeleri ilçe merkezinden alıp köye döndükten bir gün sonra söz konusu malzemeyi evinin yakınında bulunan ve bu kişilerce tarif edilen yere bırakarak teslim almalarını sağlar.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıdaki gerekçe ile, bu olayda S'nin TCK, m. 28 hükmünden yararlanamayacağına karar vermiştir:

Söz konusu olayda terör örgütü mensubu silahlı kişilerin "S'yi **tehdit** ettikten sonra evden ayrılmış olmaları, böylece tehdit eyleminden söz konusu malzemelerin teslim edildiği ana kadar geçen bir günlük süre zarfında örgüt mensuplarınca yapılan tehdidin ağırlığını ve korkutucu etkisini kaybetmesi, bu süre içerisinde köyden ayrılıp ilçe merkezine giden S'nin olayla ilgili ihbarda bulunma ve örgüt mensuplarını yakalatma olanağına kavuşmasına rağmen bu yola başvurmayarak suça konu malzemeleri alıp örgüt mensuplarına teslim etmesi ve olaydan sonra da ihbarda bulunmaması karşısında, örgüt mensuplarınca gerçekleştirilen tehdidin başta ağır ve korkutucu etkisinin bulunduğu kabul edilebilir ise de bu etkinin suça konu malzemelerin örgüt mensuplarına teslim edildiği ana kadar devam etmediği ve S'nin bu tehdidin etkisinden geçici süreyle de olsa kurtulduğu anlaşılmakla; S'nin maruz kaldığı **tehdidin** örgüte yardım etme **kastını ortadan kaldıracak nitelikte karşı koyamayacağı veya kurtulamaya-**

G. Hukuka Aykırı ve Fakat, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi

Yeni TCK'nın 24. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, ülkemizdeki yaygın hukuk anlayışına göre, bir "hukuka uygunluk nedeni" oluşturan ve "yetkili merciin emrini ifa" olarak ifade edilen; ancak, esasında kusurluluğu

çağı ağır ve muhakkak nitelikte olmadığından, sanığa atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun unsurlarının oluştuğunun kabulü gerekmektedir."

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kusurluluğu kaldıran cebir ve tehdit etkisinde hareket etmeye ilişkin TCK, m. 28 hükmünü uygularken genişletici yorum yöntemini işletmek gerekir. Tehdit edenlerin terör örgütü mensubu silahlı kişiler olduğunu ve mensup oldukları terör örgütünün S'nin ikamet ettiği yerleşim bölgesinde varlığını sürdürdüğü vakıalarını göz önünde bulundurmak gerekir. Aksi takdirde bu içtihatlar terör örgütüne insan devşirme sonucu doğurur.

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, söz konusu karar gerekçesi, maddi ceza hukuku bakımından da tutarsızdır. Cebir veya tehdit etkisinde kalınarak bir fiilin işlenmesi halinde, maruz kalanın cebir veya tehdit, bu fiile ilişkin kastı ortadan kaldırmaz, sadece kusurluluğu etkiler. Dolayısıyla, söz konusu olayda TCK, m. 28 hükümlerinin uygulanması halinde de terör örgütüne yardım suçunun oluşacağını ve fakat, yardım eden kişinin maruz kaldığı cebir veya tehdidin etkisiyle kusurunun bulunmadığını kabul etmek gerekirdi.

II. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.2.2019 tarihli ve E. 2017/1104, K. 2019/137 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; ayrılıkçı terör örgütünün faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölgede bir köy kırsalında eşi ve eşinin ağabeyiyle birlikte oturan A'nın evine gece geç saatlerde silahlı vaziyette gelen terör örgütü mensupları, bir miktar (330 TL) para vererek, ihtiyaç duydukları bazı gıda ve sair malzemeyi satın alıp kendilerine getirmesi için A'yı sabahleyin ilçe merkezine gönderirler. A da sipariş verilen malzemeleri satın alır. Ancak, kendisine verilen para yetersiz kalınca cebinden 50 TL daha harcar. A, temin ettiği bu malzemeleri evine gelen ve kendisi dönünceye kadar evinde kalmaya devam eden örgüt mensuplarına verir.

Bu olayla ilgili olarak merciler arasında A'nın terör örgütüne yardım suçundan dolayı mı yoksa terörizmin finansmanı suçundan dolayı mı mahkum edilmesi gerektiği tartışma konusu olmuştur. Sonuçta kişinin terörizmin finansmanı suçunu işlediği kabul edilerek hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilmiştir.

Ancak, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyelerinden birinin karşı oyuna ilişkin gerekçenin dışında, bu olay bağlamında mercilerce verilen kararların hiçbirinde, A'nın içinde bulunduğu koşullar itibarıyla başka türlü hareket etme imkan ve iktidarının bulunup bulunmadığı tartışılmamıştır.

Bu tarz uygulamalar, ancak terör örgütünün amaçlarına hizmet eder ve bölge halkının terör örgütünün korkutucu gücüne boyun eğmesini sağlar.

⁸²⁹ Etrafı duvarla çevrili müstakil bir evde oturmakta olan A, hırsızlığa karşı güvence olarak evinin bahçesinde saldırgan bir köpek besler. B, hırsızlık amacıyla gece vakti ihata duvarını aşarak evin bahçesine girer. Bunun üzerine köpek, B'ye saldırır. Ancak B, silahla ateş ederek, saldırısına maruz kaldığı köpeği öldürür. Bu olayda B, köpeği öldürmek suretiyle A'ya karşı mala zarar verme suçunu işlemiştir. Ancak, bu suç bakımından, B **zorunluluk halindedir**. Hayatına veya vücut bütünlüğüne yönelik el an gerçekleşmekte olan bir **tehlike** mevcuttur. B, bu tehlikeden kurtulmak için tehlikenin kaynağını oluşturan köpeği öldürür. Bu durumda B'yi zorunluluk halinden yararlandırmak gerekir.

Köpeğe izafe edilebilecek bir haksızlık olamayacağı için, köpekle bağlantılı olarak "haksız saldırı" ibaresi kullanılamaz. Bu nedenle, köpek saldırısı karşısında meşru müdafaaya ilişkin hükümleri değil, zorunluluk haline ilişkin hükümleri göz önünde bulundurmak gerekir.

B'nin hırsızlık amacıyla konuta girmeye çalışması, maruz kaldığı köpek saldırısı karşısında, zorunluluk haline ilişkin hükümlerden yararlanmasına engel teşkil etmez.

ortadan kaldıran bir neden olan, *hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi* hali düzenlenmektedir.

Hiyerarşi, belli bir örgüt yapısı içerisinde görev yapan şahıslar arasında mevcut olan astlık-üstlük ilişkisini ifade etmektedir. Bu ast-üst ilişkisinin tabî sonucu olarak; “üst”ün yetkileri, buna karşılık, “ast”ın yükümlülükleri mevcuttur. Hiyerarşi ilişkisi, “üst”ün “ast”a emir verme yetkisini mündemiçtir. Bir başka ifadeyle; hiyerarşi, emir verme temeline dayanmaktadır. Bu yapı içinde yer alan şahıslar, “*amir*” (emreden) veya “*memur*” (emredilen) konumundadır.⁸³⁰

Bu hiyerarşik yapı içinde “amir”in “memur”a verdiği emrin hukuka uygun olması halinde, verilen bu emrin emredilen tarafından icrası da hukuka uygunluk arzedecektir. Bu itibarla, şayet amirin emri hukuka uygun ise, ifa şartlarına bağlı kalmak kaydıyla, bu emrin ifasının hukuka aykırılığından bahsetmek mümkün olmayacaktır.⁸³¹ Bu durumda, maddenin birinci fıkrasında düzenlenen *görevin yerine getirilmesi* hukuka uygunluk nedeni söz konusu olacaktır. Örneğin yeni (5271 s.) Ceza Muhakemesi Kanununa göre, “*Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler.*” (m. 119, f. 1). Bu itibarla, Cumhuriyet savcısının yazılı emrinin varlığı durumunda kolluk görevlilerinin arama yapması, görevin yerine getirilmesinden ibarettir.

Amirin emrinin *hukuka aykırı* olmasına rağmen, bu emir emredilen açısından *bağlayıcı* olabilir.⁸³² Hukuka aykırı ve fakat, bağlayıcı olan emrin emredilen tarafından icrasının hukuki esasının izahı bir mesele teşkil etmektedir.

Anayasa’ya göre; kamu görevlileri, görevlerini ifa ederken amiri durumundaki kişilerden aldıkları emirleri hukuka aykırı bulmaları halinde, bu emri “*yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir*”ler (1982 Anayasası, m. 137, f. 1, cümle 1).

Ancak, emir hukuka aykırı olmakla beraber, amir “*emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz*” (1982 Anayasası, m. 137, f. 1, cümle 2).

Türk hukukunda hakim olan kanaat; Anayasa’da belirtilen bu şartların yerine gelmesi halinde, verilen emrin, hukuka aykırı olsa bile, yerine getirilmesini, emredilen açısından “hukuka uygun” kabul etmektedir (Bir “*hukuka uygunluk sebebi*” olarak “*yetkili merciin emrini ifa*”)⁸³³.

⁸³⁰ Hiyerarşi kavramı hakkında bilgi için bkz. GÜNAL, Yılmaz: *Yetkili Merciiin Emrini İfa*, Ankara, 1967, sh. 71 vd. Ayrıca, genel bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Askerî Hiyerarşide Emirlerin Bağlayıcılığı ve Bunun Hukuki Sonuçları*, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi Sempozyumu 20-21 Haziran 1996 [TEBLİĞLER], 1996, sh. 105 vd.

⁸³¹ GÜNAL, sh. 144, 181.

⁸³² Toroslu, “bağlayıcı gayri meşru emir”den söz etmektedir (TOROSLU, Ceza Hukuku, sh. 81).

⁸³³ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 761 vd. ÖNDER II, sh. 193 vd.; ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 166 vd.

Ancak, yeni TCK'ya göre; bu ihtimalde emri yerine getiren açısından bir hukuka uygunluk sebebi değil⁸³⁴, bir *sorumsuzluk sebebi*; bir başka ifadeyle, bir *mazeret sebebi* söz konusudur⁸³⁵. Bizatihi hukuka aykırı olan emir, ifa zorunluluğu getiren hükümle emredilen açısından hukuka uygun hale getirilmemektedir. Böyle bir durumda emrin ifası da hukuka aykırılık vasfını muhafaza etmektedir⁸³⁶. Ancak, emredilenin içinde bulunduğu hiyerarşik yapı dolayısıyla, belli bir merasime bağlı kalınmak kaydıyla, bizatihi hukuka aykırı olan bir emrin yerine getirilmesi, bu emredilen açısından bir *mecburiyet* olarak tezahür etmektedir⁸³⁷. Böyle bir durumda, hukuka aykırı emri veren amir karşısında, amirin bu emri karşısında emredilenin söz konusu emrin ifasına ilişkin irade hürriyetinin mevcut olmadığı normatif olarak kabul edilmektedir ve bundan dolayı, emri ifa edenin sorumluluğu cihetine gidilmemektedir. Bu durumda sorumluluk, emri verene aittir⁸³⁸.

Yeni TCK'nın, amirin hukuka aykırı emrinin ifasının bir hukuka uygunluk sebebi teşkil etmediği hususundaki bu kabulü Anayasamızın ifade tarzına da uygundur. Anayasa, böyle bir durumda emri yerine getiren “sorumlu olmaz” ifadesini taşımaktadır. Yeni TCK'nın 24. maddesinin ikinci fıkrasında da “yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz” denilmektedir.

Yeni TCK'nın 24. maddesinin bu düzenlemesi karşısında, hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesini, *kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak* kabul etmek gerekir. Aynı düşünceyle, yeni CMK'nın 223'üncü maddesinde, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması halinde beraat kararının verilebileceği belirtildikten sonra (f. 2, bent d); “*yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etki-*

⁸³⁴ GÜNAL, sh. 57, 143, 182.

⁸³⁵ Bu hususta bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Emniyet Görevlilerinin Silah Kullanma Yetkisi Üzerine Düşünceler*, in: İstanbul Barosu Dergisi, cilt 68, yıl 1994, sayı 1-2-3 (Ocak, Şubat, Mart), sh. 99 vd.; MERAKLI, Ceza Hukukunda Kusur, sh. 376.

⁸³⁶ *Erem* de, Hukuka aykırı ve fakat, bağlayıcı emre kusurluluğu kaldıran sebepler arasında yer vermektedir (EREM, Genel Hükümler II, sh. 1 vd., ayrıca, 12 vd.). Ancak, *Erem*, meselâ meşru müdafaya da kusurluluğu kaldıran sebepler arasında yer vermek suretiyle (EREM, Genel Hükümler II, sh. 1 vd. ve sh. 21 vd.); Hukuka uygunluk sebepleriyle kusurluluğu kaldıran sebepler arasındaki ayırımı inkâr etmektedir. *Erem*'in bu fikrine iştirak etmemiz mümkün değildir.

⁸³⁷ “Mecburiyet”, belli bir hususta kişinin iradesinin zorlanmışlık halinin mevcudiyetini ve dolayısıyla, irade hürriyetinin ortadan kalktığını ifade etmektedir. Bu nedenle, “mecburiyet” halinde işlenen fiil hukuka aykırı olma vasfını muhafaza etmektedir. Ancak, belli bir hususta mecburiyet halinde hareket eden kişinin bu hususa ilişkin irade hürriyetinin olmadığı - *normatif olarak* kabul edilmektedir ve dolayısıyla, böyle bir durumda mesele kusurluluk açısından tetkike tabi tutulmalıdır. Halbuki yükümlülük, kişinin belli bir davranış normu karşısındaki vecibesini ifade etmektedir.

⁸³⁸ Mevzuatımızda bu husustaki hükümler açısından bkz. 2559 s. Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, m. 2, fıkra 2; 657 s. Devlet Memurları Kanunu, m. 11, fıkra 2.

siyle işlenmesi” hallerinde, kusurun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilebileceği (f. 3, bent b) hüküm altına alınmıştır. CMK’nın bu düzenlemesi de göz önünde bulundurulduğunda, mevzuatımızca hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesinin, *kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak kabul edildiği* açık bir şekilde görülecektir⁸³⁹.

Amirin emri, hukuka aykırı olmanın yanı sıra, ayrıca suç da teşkil edebilir. Anayasa, konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesine “*hiçbir surette*” müsaade etmemektedir (m. 137, fıkra 2)⁸⁴⁰. Yeni TCK’nın 24. maddesinin üçüncü fıkrasında da aynı ilkeye yer verilmiştir:

*“Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.”*⁸⁴¹.

Emrin konusunun suç teşkil etmesi halinde, kişinin bu emri yerine getirmesi, içinde bulunduğu hiyerarşik yapı, emir-komuta zinciri, ast-üst ilişkisi dolayısıyla mazur görülemez. Bir başka ifadeyle, konusu suç teşkil eden emri yerine getiren kişinin soyut hiyerarşik yapı dolayısıyla bu emrin yerine getirilmesine ilişkin irade hürriyetinin tamamen bertaraf edildiğini ve hatta, zayıflamış olduğunu söylemek mümkün değildir. Bir Hukuk Devletinde bu tür ihtimallerden bahsedilemez. Konusu suç teşkil eden emri yerine getiren emredilen, bu suçun faili olması itibarıyla, sorumlu tutulacaktır. Emreden kişi ise, bu durumda sadece azmettiren olarak emredilenin işlediği suçtan dolayı sorumlu tutulacaktır. Ancak, emreden durumundaki kişinin hiyerarşik ilişkisinin yanı sıra şahsi nüfuz kullanmak suretiyle konusu suç teşkil eden bir emri rahatlıkla ifa ettirebileceği hallerin mevcudiyeti de gözönünde tutulmalıdır. Dikkat edilmelidir ki, bu hallerde emredilenin konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesi hususunda irade hürriyetinin zayıflamasına ve hatta tamamen bertaraf edilmesine etkili faktör, soyut hiyerarşik ilişki değil; amir durumundaki kişinin görevini kötüye kullanmak suretiyle tatbik ettiği şahsi nüfuzdur.

Anayasa’nın 137. maddesinin 2. fıkrasında, “*konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz*”

⁸³⁹ Ancak, yeni TCK yürürlüğe girdikten sonra Türk ceza hukuku doktrinde bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı yazarlar inatla, mülga 765 s. TCK döneminde olduğu gibi bu durumda bir hukuka uygunluk nedeni bulunduğunu ileri sürmeye devam ederler (DEMİRBAŞ, Genel Hükümler [10], sh. 271; SOYASLAN, Genel Hükümler [7], sh. 363). Bazı yazarlar ise, kusurluluğu etkileyen sebeplerle mazeret sebepleri arasında bir farklılık bulunduğunu ileri sürerler. Bu yazarlarca, kusurluluğu etkileyen sebeplerden farklı olarak, mazeret sebeplerinin varlığı halinde fiilin haksızlık içeriğinde de bir azalma meydana geldiği kabul edilmektedir (ÖZBEK/DOĞAN/BACAK-SİZ/TEPE, Genel Hükümler [7], sh. 424 vd.; MERAKLI, Ceza Hukukunda Kusur, sh. 376).

⁸⁴⁰ GÜNAL, sh. 139, 182.

⁸⁴¹ Ayrıca bkz. 2559 s. Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, m. 2, fıkra 2, cümle 3; 657 s. Devlet Memurları Kanunu, m. 11, fıkra 3.

prensibi konulurken; son fıkrasında, “*askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır*” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler karşısında Kanun koyucuya tanınan *istisna* getirme imkanı, ancak birinci fıkradaki kural açısından söz konusu olabilir. Birinci fıkra hükmüne göre, konusu suç teşkil etmemekle beraber, hukuka aykırı olan emir yazılı olarak tekrarlanırsa, emredilen kişi bu emri yerine getirmeye *mecbur*dur. Hukuka aykırı emrin ancak yazılı olarak tekrarlanması halinde, mecburiyetin varlığı normatif olarak kabul edilmektedir. Bu kurala getirilebilecek istisna ile, konusu suç teşkil etmemekle beraber, muhteva olarak hukuka aykırı olan bir emrin yerine getirilmesi için yazılı tekrar şartı aranmayabilecektir. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, m. 2, f. 3 hükmü, bu istisna çerçevesinde mütalâa edilmelidir. Bu hükme göre, 13 bent olarak sayılan hallerde “*yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenemez*”.

Nitekim, yeni TCK’da da bu kabulden hareketle,

“*Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.*”

hükmüne yer verilmiştir (m. 24, f. 4).

Silahlı Kuvvetler, hiyerarşik ilişkinin en fazla hissedildiği müessesedir. Bu hiyerarşi, “*mutlak itaat mecburiyeti*” ile tezahür etmektedir:

“*Ast; ... âmirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine **mutlak itaate mecburdur***”((4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, m. 14, f. 1).

Askerî hiyerarşide hizmetle münasebetli hususlarda ve hizmetin gereği olarak vaki olan emirlere *itaat yükümlülüğü* mevcuttur. Hatta, bu hiyerarşi içinde verilen emre *mutlak itaat mecburiyeti* vardır.

İç Hizmet Kanununun bu düzenlemesine göre, *maiyet* veya *ast*, *amir* veya *üstün* emrinin⁸⁴² hizmetle münasebetinin olup olmadığını, hizmetin gereği olup olmadığını araştırmaksızın, bu emre itaate mecburdur.

Bu mutlak itaat mecburiyetinin sonucu olarak; “*mübrem ve müstacel bir zaruret ve tehlike halinde verdiği emirlere itaat ettirmek için bir mafevk tarafından yapılan müessir fiiller, makam ve memuriyet nüfuzunu suistimal telâkki edilmez ve suç sayılmaz. ./. Bu hüküm harbde veya eşkiya müsademeleri ve isyan yahut askerlik harekâtı ve mücrim takibatı gibi vazifeler başında mübrem surette elzem bir itaati temin için başka vasıtalar bulunmadığı takdirde bir subayın madunun ısrar ve mukavemetine karşı silah kullanmaya mecbur kalması halinde de caridir*” (22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, m. 119, f. 1 ve 2).

⁸⁴² Bu kavramlar için bkz. TSK. İç Hizmet Kanunu, m. 9 ve 10.

Hemen ifade edilmelidir ki; bu hükümlerin uygulanırılığının hukuki izahı bir hayli güçtür. Bir Hukuk Devletinde, hizmet gereği olarak verilen ve hukuka uygun olan emirlere itaati temin edecek başka hukuki çarelerin aranması gerekir.

Maiyet veya astın hukuka aykırı olmasına rağmen itaate mecbur olduğu emrin icrasından “*doğacak mesuliyetler emri verene ait*” olacaktır (211 s. İç Hizmet Kanunu, m. 14, f. 2, cümle 2). Çünkü, “*amir maiyetine hizmetle münasebeti olmayan emir veremez*” (211 s. İç Hizmet Kanunu, m. 16, cümle 1). Aksi davranışta bulunanlar, *disiplin cezasıyla* cezalandırılırlar (16.6.1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun, m. 53).

Buna karşılık, Askerî Ceza Kanunu’nda yer alan **kurala** göre, “***hizmete müteallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse, bu suçun işlenmesinden emir veren mesuldür***” (m. 41, f. 2). Buna göre, konusu suç teşkil etse bile, kural olarak astın emre itaat etme mecburiyeti vardır. Bizatihî emrin konusu suç teşkil ettiğine göre, bu emrin icrası ast açısından bir hukuka uygunluk sebebi değil, bir “*mazeret sebebi*” teşkil edebilir. Bir başka ifadeyle, hukuka aykırı olan emri icra etmeye *kanunen mecbur* edilen ast, bu emrin icrası dolayısıyla ancak kusurlu telakki “*edilemez*” denebilir. Bu konuda tek kısıtlayıcı ölçüt, emrin “***hizmete müteallik hususlarda***” verilmiş olmasıdır. Bu itibarla, hizmete müteallik olmayan bir hususta verilen emir, konusu suç teşkil ettiği takdirde ast bu emri yerine getirmeyecektir^{843,844,845}. Ancak, “***hizmete müteallik hususlarda***” verilmiş ve fakat bizatihî suç teşkil eden bir emri icra etmek mecburiyetinde olan astı, işlenen bu suç dolayısıyla kusurlu “*addedemeyeceğiz*” ve “*cezalandıramayacağız*”. Fakat, bizatihî suç teşkil eden emrin icrası, herhalde *hukuka aykırı* olmak vasfını muhafaza etmektedir.

⁸⁴³ Bir askeri faaliyet sırasında üst A, talimatlara riayet etmeyen ast B’ye bir diğer ast C tarafından tokat atılmasını emreder. C de bu emir üzerine B’ye birkaç tokat vurur. Bu minval üzere cereyan eden olayla ilgili olarak Askeri Yargıtay, C bakımından da ceza sorumluluğu cihine gidilmesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur: Askeri Yargıtay, 23.6.2009, E. 2009/13, K. 2009/5.

Kanaatimizce de burada, hizmete müteallik bir hususta verilmiş emir söz konusu olmadığı için, konusu suç teşkil eden emri yerine getiren ast da ceza hukuku bakımından sorumlu tutulmalıdır.

⁸⁴⁴ Bu bağlamda önemle işaret etmek gerekir ki, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs (TCK, m. 311, 312) suçlarının işlenmesi zımında verilen emirler, “***hizmete müteallik hususlarda***” verilmiş emirler değildir. Bu emirleri yerine getirmesi bağlamında bir mazeret sebebinden söz edilemez. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsüne iştirak eden üstler tarafından söz konusu teşebbüs bağlamında astlara verilen emirler, bu çerçevede değerlendirilmelidir.

⁸⁴⁵ Yargıtay 9. Ceza Dairesi, “Balyoz Davası” olarak bilinen davada verilen mahkumiyet hükmünün temyizen incelemesi sonucunda verdiği kararda, bu düzenlemelerden habersiz bir şekilde **gerçeği yansıtmayan** tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

“*Anayasamızın 137. maddesinde yer alan ‘Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilemez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz’ şeklindeki hükme askeri hizmetlerin görülmesi için kanunla getirilen bir sınırlama bulunmamaktadır.*”: 9.CD. 9.10.2013, E. 2013/9110, K. 2013/12351.

Demek ki; “hizmete müteallik hususlarda verilen” emrin konusu suç teşkil etmesine rağmen, icrası ast açısından bir *kanunî mecburiyet* arz etmektedir. Bu nedenle, böyle bir emri icra eden astın cezaî sorumluluğu cihetine gidilemeyecektir. Ancak, hemen ifade etmemiz gereki ki; bu iki unsurun birbiriyle telifi hukuken hayli güç bir husustur. Yani, bir emir hem *suç* teşkil edecek, hem de “*hizmet gereği*” olacak! Böyle bir düzenlemenin bir Hukuk Devletinde kabulü mümkün değildir. Ayrıca, belirtmek gerekir ki, bu hüküm, Anayasanın “*konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez*” şeklindeki hükmüne (m. 137, f. 2) aykırıdır.

Askerî hiyerarşideki bu kuralın bir diğer istisnası, “*amirin emrinin adli ve askerî bir suç maksadı ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu(nun astın) kendisince malûm*” olmasıdır (AsCK., m. 41, f. 3, bend B).

Buna göre; kendisine verilen emrin bir *suç işlemek maksadıyla verildiğini biliyorsa*, ve buna rağmen emri yerine getirmişse, astın da cezaî sorumluluğu cihetine gidilecektir. Dikkat edilirse, emrin “*hizmete müteallik bir hususta*” verilmiş olmasının yanı sıra; ast, bu emrin bir suç işlemek maksadıyla verildiğini bilecektir. Ast, ancak bu durumda cezalandırılabilir. Bu itibarla; verilen emir açıkça bir suç teşkil etse bile; ast bu emrin hizmet gereği olarak değil de, *suç işlemek maksadıyla verildiğini bilmiyorsa*, sorumlu tutulmayacaktır⁸⁴⁶.

Verilen emrin konusunun suç teşkil etmesine rağmen, emre muhatap olan astın, amirinin bu emri suç işlemek maksadıyla verdiğini bilmiyorsa, emri yerine getiren astın ceza hukuku sorumluluğundan söz edilemez. Zira bu durumda astın suç işleme kastından söz edilemez.

Yukarıda da izah edildiği gibi; ast açısından itaat mecburiyeti getirilen emir, konusu *suç* teşkil etmesine rağmen, “*hizmete müteallik hususlarda verilen emir*”dir. Eğer, konusu suç teşkil eden emir, hizmet gereği olarak verilmişse!; ast, bu emre itaat etmek “*mecburiyetindedir*”.

Emir, hizmete ilişkin bir hususta verilmiş değilse ya da “*adli ve askerî bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik*” ise ve ayrıca; ast, emrin bir suç işlemek maksadıyla verildiğini biliyor ise; bu halde artık astın verilen emre itaat mecburiyeti yoktur. Buna rağmen ast emri icra ederse, cezaî sorumluluktan kurtulamayacaktır. Kanunun kabul ettiği sisteme göre, ast bu suçtan amir veya üstüyle beraber *müşterek fail* sıfatıyla sorumlu tutulacaktır (AsCK., m. 41, f. 3).

Emrin hizmet gereği olarak verilmediği ve ayrıca bir suç teşkil ettiği açık seçik anlaşılmasına rağmen; astın bu emrin bir suç işlemek maksadıyla verilmiş olduğunu bilmemesi ihtimali mevcuttur. Bir emrin suç teşkil ettiği açık seçik anlaşıl-

⁸⁴⁶ 28 Aralık 2011 tarihinde, kaçakçılıkla işgal ettikleri belirtilen 34 kişinin Uludere’de gece saatlerinde Irak sınırından ülkemize giriş yaparken Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bombalanmak suretiyle öldürülmesi olayında, aldıkları emir üzerine bombalamayı gerçekleştiren pilotların ceza hukuku sorumluluğunu bu bağlamda ele alıp değerlendirmek gerekir.

labilir; ancak, bu emri veren amir veya üst bir suç işlemek maksadı gütmeyebilir veya bu maksadın güdüldüğü ast tarafından bilinmeyebilir. Verilen emrin suç teşkil ettiğinin açık seçik anlaşılmasından bu emri verenin suç işlemek maksadı güttüğü sonucu zorunlu olarak çıkarılamaz⁸⁴⁷.

Burada dikkat edilecek diğer nokta; astın cezaî sorumluluğu cihetine gidebilmek için amiri tarafından verilen emrin bir suç işlemek maksadıyla verildiğinin biliniyor olmasıdır. Yani, buradaki bilmek, **doğrudan bilmeyi** ifade etmektedir. Mevcut kanunî düzenleme karşısında; bu maksadın muhtemel görülmesi veya öngörülebilir, tahmin edilebilir olması, bilmek olarak mütalâa edilemez.

H. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması

Yeni TCK'nın 27. maddesinin birinci fıkrasında ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın aşılması düzenlenmiştir. Bilindiği gibi, yeni TCK'nın sisteminde ceza sorumluluğunu kaldıran nedenler ana başlığı altında *hukuka uygunluk nedenleri* ve *kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler* mütalâa edilmektedir.

Her ne kadar, maddenin birinci fıkrası hükmüyle ilgili gerekçede bu fıkra da “*ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerin hepsini kapsamına alacak surette sınırın kast olmaksızın aşılması hâli düzenlenmiştir.*” ifadesine yer verilmiş ise de; bu fıkra hükmünün sadece **hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması** olarak anlamak gerekir⁸⁴⁸.

Hukuka uygunluk sebeplerinin dışında, ceza sorumluluğunu kaldıran diğer nedenler ise, kusurluluğu kaldıran nedenlerdir. Bunlardan örneğin zorunluluk hali, işlediği fiille ilgili olarak kişinin sadece hukukun gereklerine göre davranışlarını yönlendirme yeteneğini etkilemektedir. Aslında zorunluluk halinde iken kişi kasten hareket etmektedir. Bu nedenle, bir olayda hem zorunluluk halinin varlığından hem de taksirle işlenen bir suçtan söz edilemez. Sonuç olarak, kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerle ilgili olarak sınırın aşılması söz konusu değildir.

Hukuka uygunluk nedeninde sınırın aşılması durumunda, bir hukuka uygunluk nedeni gerçekte mevcuttur. Ancak var olan hukuka uygunluk nedeninin sınırı aşılmıştır. Bu durumda, işlenen fiil bütünüyle hukuka aykırı değildir; sadece sınırın dışında kalan hareketler hukuka aykırı olmakta devam etmektedir⁸⁴⁹.

Hukuka uygunluk nedeninin sınırı *kasten* aşılmış olabilir. Bu durumda artık bir hukuka uygunluk nedeninin varlığının bir önemi yoktur. Kişi, kasten işlediği suçtan dolayı sorumlu tutulur.

⁸⁴⁷ Benzer bir düzenleme, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulmasına Dair Roma Statüsü'nün 33. maddesinde yer almaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. DE-ĞİRMENCİ, Olgun: *Uluslararası Ceza Hukukunda Amirin Emrini İfa Sorumluluğu*, in: Legal Hukuk Dergisi, sayı 120, Aralık 2012.

⁸⁴⁸ Ayrıca bkz. KOCA, Ceza Hukuku Dergisi, Ekim 2006, sh. 141 vd.

⁸⁴⁹ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 699; KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 153.

Örneğin, belli bir sağlık sorunu olduğu için tedavi amacıyla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişi üzerinde, bu kuruluştaki sağlık görevlileri tarafından, bilgi ve rızası dışında, şikayeti ve tedavisiyle alakası olmayan bir hususla ilgili olarak bilimsel deney yapılması durumunda, hukuka uygunluk nedeninin varlığının bir önemi kalmamaktadır. Kişinin vücudu üzerinde böyle bir müdahale, ilgili sağlık görevlilerinin yeni TCK'nın 90. maddesine göre ceza sorumluluğunu gerektirmektedir.

Keza, “zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.” (m. 256, f. 1). Bu maddenin gerekçesinde, ayrıca izaha gerek bırakmayacak biçimde, şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Bazı kamu görevlileri, görevlerinin gereği olarak zor kullanma yetkisiyle donatılmışlardır. Örneğin emniyet görevlileri, suç şüphesi altında bulunan kişiyi yakalamak yetkisiyle donatılmıştır. Yakalanan kişi, gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için, emniyet görevlisinin görevinin gereği olarak ve mevzuattan kaynaklanan talimatlarına uygun davranmak yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğe aykırı davranan kişinin örneğin hâkim veya savcı huzuruna çıkarılmamak için direnmesi hâlinde, emniyet görevlilerinin zor kullanarak bu kişiyi hâkim veya savcı huzuruna çıkarabilirler. Keza, bir meydanda hukuka uygun olmayan, örneğin gece yarısı gösteri yürüyüşü yapmak isteyen kişilerin, dağılmaları hususunda çağrıda bulunan emniyet görevlilerinin bu çağrısına rağmen, dağılmasını sağlamak amacıyla kuvvet kullanılabilir. Kullanılan zorun, birinci örnekte suç şüphesi altında bulunan kişinin hâkim veya savcı huzuruna çıkmamak konusundaki direncini kırmaya yetecek ölçüde, ikinci örnekte ise hukuka aykırı gösteri yürüyüşü yapan kişilerin dağılmasını sağlamaya yetecek ölçüde olması gerekir. Bu ölçünün dışında kuvvet kullanılması durumunda, bunun ceza sorumluluğunu gerektireceği muhakkaktır. Örneğin hukuka aykırı gösteri yürüyüşü yapan kişilerin dağılmamakta direnmenin ötesinde, kamu görevlilerine karşı bir saldırıda bulunmamalarına rağmen, bu kişilere karşı vücutlarının yaralanmasını sonuçlayacak şekilde silah kullanılması hâlinde, emniyet görevlileri açısından artık hukuka uygun bir davranışın varlığından söz edilemez. Bu durumda, zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlilerinin, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılması gerekmektedir. Ancak, bunun için, emniyet görevlisinin kasten hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde, sorunun hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılmasına ilişkin hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.”

Hukuka uygunluk nedeninin sınırı taksirle de aşılmış olabilir. 27. maddenin birinci fıkrası bu durumlara ilişkin düzenleme getirmektedir. Yani, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olsaydı hukuka uygunluk nedeninin sınırı aşılma-

yacaktı diyebileceğimiz durumlarda, sınırın taksirle aşılması söz konusu olmaktadır.⁸⁵⁰

Örneğin yeni CMK'nın 119. maddesi hükmüne göre, hakim kararında veya C. savcısının yazılı emrinde belirtilen işyerinde arama yapılması gerekirken, kolluk görevlileri tarafından gerekli dikkat ve özen gösterilmeyerek kişinin işyerinin bitişiğindeki konutunda da arama yapılması halinde, hukuka uygunluk nedeninin sınırı taksirle aşılmış olmaktadır.

Keza, 91. madde hükmüne göre, yakalanan ve hakkında C. savcısı tarafından gözüaltına alınmasına karar verilen kişi, “yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu (olan ve fakat oniki saatten fazla olamayacak) süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saat” süreyle hürriyetinden yoksun bırakılabilir. Gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi nedeniyle söz konusu süreler zarfında kişinin hakim veya mahkeme huzuruna çıkarılamaması halinde, bu hukuka uygunluk sebebinin sınırı taksirle aşılmış olmaktadır.

Hukuka uygunluk sebebinde sınırın taksirle aşılmış olması halinde ceza sorumluluğu cihetine gidilebilmesi için, fiilin taksirle işlenmesinin de kanunda suç olarak tanımlanması gerekir.

Bu itibarla, yukarıdaki iki örnekte konut dokunulmazlığının ihlali (m. 116) ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (m. 109) suçları ancak kasten işlenen suçlar olduğu için, hukuka uygunluk nedeninin sınırını, kasten değil de, taksirle aşan kolluk görevlilerinin cezalandırılması cihetine gidilemeyecektir. Bu gibi durumlarda ancak tazminat sorumluluğu söz konusu olabilir.

Buna karşılık, zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlileri, bu yetkiyi kullanırken gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek sınırı aşması halinde, taksirle yaralama suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır. Ancak, bu durumda kişi hakkında bu “*taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altında birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur.*” (m. 27, f. 1).

Böylece, Türk doktrininde hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasına ilişkin “İstanbul okulu”nun görüşü kanun metninde benimsenmiş olmaktadır⁸⁵¹.

⁸⁵⁰ Hz. Musa, gençlik yıllarında saldırıya uğradığını iddia eden bir kişinin yardım talebi üzerine saldırganın saldırısını engellemek amacıyla müdahale ettiği olayda, saldırgana vurduğu bir yumrukla ölümüne sebebiyet verir (Kur'an, Kasas [28], Ayet 15).

Bu olayda, Hz. Musa, saldırıya uğrayan bir kişinin maruz kaldığı saldırıyı önlemek amacıyla hareket etmiştir. Bu nedenle söz konusu olayda, **üçüncü kişi lehine meşru savunma** durumu mevcuttur. Ancak bu olayda, gerçek saldırganın yardım isteyen kişi olma ihtimali de söz konusudur. Bu durumda, **meşru savunmanın maddî şartlarında hatadan** söz edilebilir.

Söz konusu olayda, saldırgana veya saldırgan olduğu düşünülen kişiye uygulanan fizikî güç, vurulan yumruk darbesi, bu kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Bu durumda, **hukuka uygunluk sebebinde sınırın taksirle aşılması** söz konusudur.

⁸⁵¹ Doktrinde bir görüş, meşru savunma dahil hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın ancak kasten aşılması halinde cezada indirim yapılabileceğini savunmaktadır (ÖNDER, Genel Hükümler

Kendisine “dur” ihtarında bulunulan şüpheli kişinin bu ihtara aldırması halinde emniyet görevlilerinin, belli şartların gerçekleşmesi kaydıyla “silah kullanması”na mevzuatımızda izin verilmiştir⁸⁵².

Kaçan şüpheli kişiyi yakalamaya matuf bu “silah kullanma yetkisi”, hukuki bir yetkidir ve dolayısıyla; bu amaca matuf “silah kullanılması” halinde kanunun hükmü icra edilmekte ve hukuka uygun davranılmaktadır.

Silahın şüpheli kişiyi yakalama amacını aşan bir tarzda kullanılması halinde, bu hukuka uygunluk sebebinin sınırı aşılmış olmaktadır.

Bu gibi durumlarda “silah kullanma” yetkisini haiz olan kişinin kastını araştırmak gerekir. Şayet kişi bu sınırı kasten aşmış ise, meydana gelen neticeden kastına göre sorumlu tutulacaktır. Burada söz konusu olan kast, doğrudan kast olabileceği gibi, muhtemel kast da olabilir. Somut olayda özellikle muhtemel kastın mevcut olup olmadığını iyi tetkik etmek gerekir. Yakalamak maksadına matuf olarak hayatî tehlike arzermeyen bir nahiyeye ateş etmek istenirken hayatî bir bölgeden, meselâ kafasından isabet alan kişinin ölmesi halinde; meydana gelen ölüm neticesi açısından muhtemel kastın varlığını söylemek pekâlâ mümkündür⁸⁵³.

II, sh. 248/249; GÖLCÜKLÜ, Feyyaz: *Suçta Kanunî Unsurun Ortadan Kalkması, Fiilin Hukuka Aykırılığı ve Hukuka Uygunluk Nedenleri Konusunda Bazı Mülahazalar*, in: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, yıl 1968, cilt XXIII, sh. 211/212; ÖZEN, sh. 163). Buna göre; meselâ fail, “mevcut saldırıdan saldırganın bacağına yaralayarak kurtulabileceğini bilmesine rağmen, onu öldürürse; sınır kasıtlı olarak aşılmıştır” (Ömek, ÖZEN, sh. 161’den iktibas edilmiştir). Özen’in fikrine göre; “50. madde hükmü olmasaydı meşru müdafanın tüm şartları gerçekleşmediğinden ve bu nedenle fiil, meşru müdafaa halinde işlenmiş sayılmayacağından faile asıl suçun cezası aynen verilecektir. İşte, kanun koyucu, bu haksızlığı 50. madde hükmünü sevk etmek suretiyle gidermeye çalışmıştır” (ÖZEN, sh. 162).

Buna karşılık, diğer bir görüşe göre; faile verilecek cezada indirim yapılabilmesi için, sınırın “taksirle” aşılması gerekir (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 841). Ancak bu “taksir”in mahiyeti hakkında, yani hangi hallerde sınırın “taksirle” aşılmış olabileceği hususunda herhangi bir açıklamada bulunulmamaktadır.

Yargıtay’ın uygulaması dikkate alındığında; özellikle meşru savunmaya ilişkin sınırın aşılması olaylarında, sınırın kasten mi yoksa “taksirle” mi aşıldığı hususunda herhangi bir araştırma yapılmaksızın, 765 s. Kanunun 50. maddesi hükmünün uygulanması gerektiği hususunda bir eğilime sahip olduğu açıkça görülür: 1. CD., 14.6.1989, 1802/1921 (YKD, Ocak 1990, sh. 109); 1. CD., 17.9.1986, 2940/3019 (YKD, Kasım 1986, sh. 1706); 1. CD., 27.11.1984, 3718/4955 (YKD, Haziran 1985, sh. 884); 1. CD., 7.12.1982, 3068/4075 (YKD, Nisan 1983, sh. 603); 1. CD., 13.12.1982, 3377/4117 (YKD, Şubat 1983, sh. 263). Hatta, Yargıtay, bir kararında “... samının, devam eden saldırılar karşısında maktul ve yakınlarının ayak nahiyelerine ateş etmek suretiyle saldırıları bertaraf etmek imkânı varken; *kasten* hayatî nahiyelere ateş etmek suretiyle ... hududu aştığı” olayda, kasten öldürme suçundan dolayı verilen cezanın hukuka uygunluk sebebi olarak meşru savunmanın sınırının aşılmış olması dolayısıyla indirilmesi gerektiği yönünde içti-hatta bulunmuştur: 1. CD., 29.1.1986, 4255/294 (YKD, Temmuz 1986, sh. 1044).

⁸⁵² Bu konudaki mevzuatımızın genel bir değerlendirmesi için bkz. ÖZGENÇ, İBD, 68(1994), sh. 90 vd.

⁸⁵³ «Aksaray Kaymakamı ve Belediye Başkanının başkanlığında oluşan bir heyetin ... Helvadere kasabasına geldikleri ve burada gerekli işleri yapıp dönecekleri sırada kadın ve çocuklardan oluşan bir grup tarafından taşla tutuldukları, önceleri az olan kalabalığın giderek artması, vasıtaları-

nın tahrip edilmesi ve beraberlerindeki güvenlik kuvvetlerinin yetersiz kalması üzerine Belediye binasına sığındıkları; ... Kaymakamın ... takviye kuvvet istediği; bir süre sonra gelen takviye kuvvetle kalabalığın havaya ateş edilerek dağıtıldığı; bundan sonra kaymakamın sözlü emri üzerine olayın elebaşısının takip ve yakalanmaları için 2-3 kişilik timler oluşturulduğu; bu arada sanık Polis memuru A'nın da polis memuru D ve Jandarma eri Y ile bir ekip oluşturularak görevlendirildikleri; en önde sanık A, onun arkasında 15-20 metre mesafede D ve bir o kadar mesafede arkada Y olacak şekilde engebeli arazide kaçanları takip ettikleri, bu sırada sanığın önünde kaçan maktül R'ye "dur" ihtarıyla bulunduğu; ancak matulün bunu dinlemeyip kaçmaya devam etmesi üzerine elindeki (akrep) tabir edilen otomatik silahla bir el ateş ettiği; yine durmaması üzerine ikinci kez ateşlediğinde arkadan başından vurup öldürdüğü ... (anlaşılmıştır).

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasında; silah kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin "teslim ol" emrine uyulmaması halinde, güvenlik kuvveti mensuplarına *doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilme yetkisi* verilmiştir. Bu yetkinin kapsam ve sınırlarını belirlemek gerekir. Sözü edilen bu hükümdeki "ateş etme yetkisi", "öldürme yetkisi" anlamına gelmez.

Anılan Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasında sözü edilen yetki, aynı maddenin 1. fıkrasından kaynaklanmaktadır. 1. fıkra "görevlilerin ... Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullanma yetkisini haiz... oldukları" hüküm altına alınmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Silah kullanılmasını gerektiren halleri ile ilgili 87. maddesinin 3. bendinde, silah kullanma tarzı "... önce ayağa, devamı halinde hedef gözetilmeksizin ..." biçiminde özetlenecek şekilde açıklanmıştır.

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16. maddesinde, polislin silah kullanmaya yetkili olduğu haller belirtilmiş, bu yetkinin kullanılma biçimi de Polis Vazife ve Selahiyet Nizamnamesinin 17. maddesinde "... polis için silah kullanmak selahiyetinin kabul edildiği hallerde, silah kullanılması, silahı kullanmaktan başka çare bulunmadığı hallere münhasırdır. Bu takdirde mümkün olduğu kadar suçlunun öldürülmekten ziyade yaralanmasına dikkat edilmesi icap eder..." şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinin 270. maddesinde, silah kullanmaktan maksadın *öldürmeyi istihdaf etmeyip*, sadece vazifenin yerine getirilmesini mümkün kılacak hale hasderildiği ve bunun için silahın lüzumu halinde kullanılmasının zorunlu olduğu, aynı nizamnamenin 271. maddesinde açıklanmıştır.

Görülüyor ki; ... 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 4. maddesi yukarıda sözü edilen kanunların belirtilen maddelerini ortadan kaldırmadığı gibi, birinci fıkrasında, güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisini, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda, Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde silah kullanmayı gerektiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku haline bağlamak suretiyle bu hükümlerin yürürlüğünü teyit etmektedir.

Sanığın, TCK'nın 49/1. maddesi hükmünü icra ederken, aynı Kanun 50. maddesi hükmünü de gözönünde bulundurması ve buna uyması gerekir. Zira TCK'nın 49. maddesindeki şartlar 50. madde ile sınırlandırılmıştır.

Sanığın, kaçan maktülü yakalamak kastıyla silah kullanması görevi gereğidir. Ancak ölmeyecek noktalara yönelterek silah kullanması gerekirken doğrudan doğruya maktülün kafasına ateş ederek vurup öldürmesi şeklindeki oluştta yukarıda açıklanan kanun hükümlerine uyulmamış ve zaruretin tayin ettiği **hudut tecavüz edilmiştir.**

... (Sanıkta öldürme kastının bulunduğu anlaşılmadığından; fiili TCK'nın 452. ve 50. maddelerine temas eder nitelikte görülmüştür.»: CGK., 6.10.1986, 199/419 (Savaş/Mollamahmut-oğlu I, sh. 669/670); aynı mealde CGK., 26.4.1982, 42/164 (Savaş/Mollamahmut-oğlu I, sh. 679/680); 1. CD., 17.11.1986, 3998/4120 (YKD, Temmuz 1987, sh. 1078).

«11.9.1981 gün ve 2524 sayılı yasaya dayanılarak çıkarılan "Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik"ın 3. ve 60. maddeleri gereğince *Genelkurmay Başkanlığı*,

Anıtkabire ilişkin her türlü hizmeti yapmakla ve *Anıtkabiri “hırsızlığa, sabotaj, baskın, yangın ve tahriplere karşı korumakla” görevlidir.*

Olay günü, Anıtkabir’in Gençlik caddesine bakan tarafında, 1-5 nolu nöbetçi kulübeleri arasında devriye nöbeti tutan sanık(k, bir şahsın) duvardan atlamak suretiyle Anıtkabir bahçesine girip Mozoleye doğru koştuğunu görünce, görevi gereği (onu) kovalamaya başla(mıştır. Kendisine) yetiştği sırada yerden aldığı taşı sanığa fırlatan (şahsın) sanığı yaralayarak yere düşür(müş) ve ikisi bir süre boğuş(muşlardır). Sanık(k), elinden kurtulmayı başaran maktulün yeniden koşmaya başla(ması üzerine,) “dur” ihtariyle havaya ikaz atışı yap(mış); maktul buna rağmen durmayınca hedef gözeterek yaptığı ateş sonucu ağır şekilde yaralan(mış ve) bir süre sonra öl(müştür). Sanığın öldürme kastıyla ateş ettiğinin kesinlikle belirlenememiştir. Merminin maktulün vücuduna giriş çıkış yerleri de gözönünde tutularak, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 87. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerin gerçekleşmesi nedeniyle **silah kullanma yetkisini kullanan sanığın, zaruretin tayin ettiği yetkiyi aştığının** kabulü ile TCK’nın 452/1., 50, 59/2. maddelerinin uygulanması suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadırlar: 1.CD, 13.3.1991, 509/700 (Savaş/ Mollamahmutoğlu I, sh. 685/686).

«Olay gecesi saat 22 sıralarında ... adlı şahsın ... Polis Karakoluna telefon ederek ... plaka numaralı ... otomobilin ... benzin istasyonuna geldiği, bu arabada bulunan kişilerin silah çekerek (kendisine) hakaretlerde bulunduğunu ve ... istikametine doğru kaçtıklarını ihbar (etmesi üzerine;) sanığın takibe geçilmesi emri alarak o istikamete gidip, ... aracı yakın mesafeden takibe başladığı; durması için çeşitli şekillerde yapılan ikazlara uymadığı ve başka şekilde durdurulamayacağını anladığı için, ... **araca doğru bir el ateş ettiği;** rastgele yapılan bu atışla her iki araç da hareket halinde olduğu için **çıkan kurşunun tesadüfen (takip edilen) araçta bulunan A’ya isabet ederek ölümüne sebep olduğu ... olayda;** polis görevlisi olan sanığın **silah kullanma şartlarının oluşması nedeniyle,** fiilin (mülga 765 s.) TCK’nın 49/1. maddesi (kanunun hükmünü icra) şartlarında değerlendirilmesi ve **fiilin aşırılığa kaçmadığının** kabulünde zorunluluk bulunduğu halde; yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.»: 1.CD, 18.10.1993, 1551/1982 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 657).

«Çevik Kuvvet Polisi olarak görev yapan sanık F’nin ... bir otunun hızla yaklaştığını gördüğünde ... ellerini havaya kaldırarak yavaşlayıp durmasını temine çalıştığı; ancak oto sürücüsünün yavaşlamadığını ve hızını da artırarak üzerine geldiğini görünce, kendisini kenara atıp silahını ikaz niteliğinde olmak üzere havaya tevcih ile birkaç defa ateşlediği; otunun ilerdeki polis barkatını da geçtiğini gördüğünde otunun tekerleklerine doğru atışlarını sürdürerek durdurabilmeyi amaçladığı, balistik incelemeye göre diğer polislerin 41, sanığın ise 13 el ateş etmesine rağmen maktül sürücünün durdurulabilmesinin mümkün olmadığı; sanıktan vaki atışlardan bir tanesinin otunun arka camından seyirle maktüle isabet ederek ölümüne sebebiyet verdiği (olayda);

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16. maddesinin F ve H fıkralarına uygun şekilde ve yetki hudutlarını aşmaz düzeyde silah kullandığı anlaşılan sanığın 12 el ateş etmesine ve bu atışlarını muhataba isabet ettirmeyen bir titizlikle yapmış olmasına karşın onun durdurulmasını temin edemediği ahvalde; tek bir mermi ile yaralamasında aşırılıktan söz edilemeyeceği; 12 merminin ikaz mahiyetinde atılmasının da sanık lehine yorumlanmak yerine aleyhte değerlendirilerek zaruret sınırını aşmak mahiyetinde kabul *edilmemesi* gerektiği; bu ahvalde sanık polis memurunun gerek içinde bulundukları teyakkuz hali ve gerekse maktulün ısrarlı kaçışıyla yarattığı kuşku ortamında silahını kullanmasının, (mülga 765 s.) TCK’nın 49/1. maddesinde tanımını bulan “yasal görevi icra” niteliğini aşmadığı sabit iken; ... (mülga 765 s.) TCK’nın 50. maddesi mucibince mahkumiyet hükmü tesisi» doğru değildir: 1. CD., 2.11.1993, 2053/2196 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 654/655).

«... Jandarma birliğinde er olup, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa göre, mülkî, adli ve askerî görevleri yapmakla mükellef bulunan sanığın, olay gecesi, çavuş M komutasında er D ile birlikte ilçe merkezinde saat 21.00-23.00 iç hizmet devriye görevi yaptığı; bu görevinin gereği ve Sıkıyönetim Komutanlığının “Şehrin içinde umumi yerlerde ve şehrin giriş ve çıkışında tesis edilen yol kapamalarında mutlaka kimlik kontrolü yapılacaktır. Şüpheli görülenler gerekli tahkikat yapıldıktan sonra bırakılacaktır” biçimindeki emri uyarınca kah-

Buna karşılık; meydana gelen netice açısından failin kastı mevcut değilse; yani meselâ meydana gelen ölüm neticesi öngörülebilir olmasına rağmen objektif özen yükümlülüğüne aykırı davranılması sonucu öngörülmemiş ise, bu netice açısından taksirle hareket etmiş demektir. Meselâ kaçan şüphelinin yakalanmasını temine matuf olarak, korkutmak için silahın başka bir yöne tevcih edilerek ateşlenmesi halinde; mermi sekmesi sonucu şüpheli şahıs yaralanmış veya ölmüş olabilir. Bu durumda, meydana gelen neticeden failin taksiri dolayısıyla sorumlu tutulması ve 27'nci maddenin birinci fıkrası hükmü gereğince cezalandırılması gerekir^{854, 855}.

veleri kontrol etmek üzere giderlerken, ... Köyü yolundan bir traktörün ilçe merkezine doğru gelmekte olduğunu gördükleri; traktörün cezaevi civarında yanlarından geçtiği sırada römorkunda odun yüklü olduğunu görünce, odunun kaçak olduğu düşüncesiyle “dur” ihtarını verdikleri; bu ihtar alan traktör sürücüsü kaçak orman emvali nakletmek suçunun sanığı durumunda bulunan maktul K'nın traktörünü durdurmayarak aracını daha süratle sürerek uzaklaştığı ve devriye ekibinin sözlü ve düdüklü ihtarlarına rağmen durmayarak kaçmaya başladığı; bunun üzerine devriye erlerinin maktulü yakalamak amacıyla traktörün arkasından 70 metre kadar koştuıkları; ancak yakalayamadıkları; bunun üzerine aralarında en süratli koşan sanığın, traktörün arkasından koşup yetişerek traktörün motor kaportasına eliyle vurmak suretiyle durmasını bir kez daha ihtar etmesine rağmen, maktulün direksiyon kırıp kaçması üzerine, bütün çabalarına rağmen durdurmaya muvaffak olamayınca, yaralamak suretiyle durdurmayı sağlamak amacıyla hamili bulunduğu tüfekte bir el ateş ettiği, sırttan girip göğüstten çıkan kurşunun ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır.

... (S)anığın sözlü ve düdüklü ihtarlarına rağmen durmayıp direksiyon kırarak kaçan maktulü yaralamak suretiyle durdurmak amacıyla atılan tek kurşun, gecenin karanlığında tesadüfen sanığın hayati önemli haiz bölgesine isabetle ölümü(ne sebep olmuştur). Ancak bu amaca kavuşmak isteyen ve traktöre ulaşip kaportasını yumruklayan sanığın, traktörün önüne geçip maktulün sağına soluna ve hayati önemi haiz bulunmayan bölgelerine, örneğin ayaklarına ateş edip onu durdurması mümkün iken, böyle yapmayarak arkasından ateş edip öl(ümüne sebep olmasına) göre, zaruret sınırını aşmak suretiyle öldürmek suçunu işlemiştir.»: CGK, 21.2.1983, 429-66 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 676/677).

«... (T)eröristlere yataklık yaptığı ihbarı (üzerine, öğretmen olan) M, ... soruşturma sırasında ... sığınak ve mağaraları göstermek için götürüldüğünde, ağaçlı ve engebeli yerde ... kaçmaya başla(mıştır. Kendisine) “dur” ihtar(ında bulunulmuş), önce havaya ateş açıl(mış ve) kaçmaya devam etmesi üzerine, serbest atış yapılmıştır. (M,) bu ateşle başından, sırtından ve bacağ(ından vurularak öl(müştür.)

(Mezkûr olayda;) 1402 sayılı Kanunun 4. maddesi ile, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 39. maddesi ve (mülga 765 s.) TCK'nın 49/1. maddesi.. dikkate alınmadan; (sanıkların) (mülga 765 s.) TCK'nın 243/1. maddesi» hükmüne istinaden mahkum edilmesi hukuka aykırıdır: 1.CD, 17.11.1993, 1396/2390 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 654).

⁸⁵⁴ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun **4.5.2010** tarihli ve E. 2009/1-249, K. 2010/108 sayılı kararına konu teşkil eden olayda, H, fabrikasının bahçesinden hurda demir çalan N'yi tabanca ile vurarak öldürür.

Yerel mahkemece; olayın, “bir kısım insanların at arabalarıyla fabrikasına gelerek hurda demirleri çaldıklarını haber alan sanığın, otomobili ile doğrudan olay yerine hareket ettiği, yolda karşılaştığı at arabalarını durdurmak istediği, bu amaçla eliyle işaret ettiği, durmamaları üzerine de tabancasıyla, önce havaya, sonra yere ve arabaların tekerleklerine olmak üzere 4 el ateş ettiği, bu atışlar sırasında yerden seken çekirdeklerden birisi ile en arkadaki at arabasında bulunan N'nin yaralandığı ve akabinde öldüğü” tarzında gerçekleştiği kabul edilmiş, Özel Dairece ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca da dosya kapsamına uygun olan bu kabule iştirak edilmiştir.

H'nın bu fiili, yerel mahkemece "olası kastla öldürme" olarak değerlendirilirken, Özel Dairece "meydana gelen ölüm, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ise, "taksirle öldürme" olarak nitelendirilmiştir.

*Olayda, kendisine ait hurda demirlerin çalındığını öğrenen sanık, bunları kurtarma çabasıyla, hurdaları çalmış olan maktûl ve arkadaşlarını bulmuş, bulduktan sonra da durdurmak istemiştir. Bu sırada, ilk olarak durmaları için işaret etmiş, kaçmakta ısrar etmeleri üzerine de önce havaya, sonra da yere ve at arabalarının lastik tekerleklerine doğru tabancasıyla ateş etmiştir. Burada, **sanığın doğrudan, yaralama veya öldürme kastı ile hareket etmediği**, Özel Dairece ve yerel mahkemece olduğu gibi, Genel Kurulca da kabul edilmektedir.*

Ceza Genel Kurulu'nun kabulüne göre, "failin, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçundan sorumlu tutulabilmesi için açıkça yaralamaya dönük bir eylemde bulunması şart olmayıp, olayın olağan seyri ve olağan gelişmesi sonucu yaralamanın meydana gelebileceğini öngörülebilir durumda olmasına rağmen hareketine devam etmesi ve ölümün bu harekete bağlı olarak meydana gelmesi de yeterlidir."

*Bu itibarla; "kendisine ait işyerinde bulunan hurda demirlerin çalınmasından duyduğu infialle, maktûl ve arkadaşlarının bulunduğu yere gelerek, at arabalarıyla kaçmakta olan maktûl ve arkadaşlarını korkutarak durdurmak gayesiyle önce havaya, sonra sürekli aynı istikamette olmak üzere at arabalarının tekerleklerine ve yere doğru birden çok kez ateş ettiği sırada, asfalttan seken kurşunlardan birisinin isabet etmesi sonucu maktûlün ölümüne neden olan sanığın eyleminin; **kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarını oluşturacağı söylenemese de, gerçekleştirilen eylemin yaralamayla sonuçlanabileceğinin öngörülmüş, buna karşılık "ölüm" neticesinin öngörülememiş olması karşısında, ... "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçunu oluşturduğunun ... kabulü gerekir.**"*

Söz konusu kararda, sorun doğru bir zeminde tartışılmamıştır.

Öncelikle sorunu, somut olayda hırsızlık suçunun tamamlanmış olup olmadığı noktasında bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekir.

Hırsızlık suçu, suçun konusunu oluşturan eşyanın sahibinin zilyetliğinden çıkarılıp, failin hakimiyet alanına girdiği anda tamamlanmış olur. Çoğu zaman, hırsızlık konusu eşya sahibinin zilyetliğinden çıkarıldığı anda failin hakimiyet alanına girmektedir. Ancak, bazı durumlarda, hırsızlık konusu eşya, sahibinin zilyetliğinden çıkarıldıktan bir süre sonra failin hakimiyet alanına girebilmektedir. Örneğin A'nın işyerinden çalınan bilgisayar malzemeleri işyerinden çıkarıldığı anda A'nın bunlar üzerindeki zilyetliği sona ermektedir. Ancak, bilgisayarlar işyerinden çıkarılmış olmakla birlikte, kovalanan hırsızın bunları bir süre sonra bırakıp kaçması halinde, bu eşya üzerinde henüz egemenlik kuramamıştır. Bu durumda hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığını kabul etmek gerekir.

Kanaatimizce, karara konu teşkil eden olayda hırsızlık suçu henüz tamamlanmamıştır. Olayda, **icrası henüz devam etmekte olan bir hırsızlık suçu** söz konusudur. Bu itibarla, olayda H bakımından icrası devam etmekte olan bir suçun işlenmesini önlemeye yönelik bir **savunma hareketi** söz konusudur. Başka bir ifadeyle, olayda H bakımından sahibi bulunduğu malvarlığına yönelik olarak işlenmekte olan bir hırsızlık suçu bağlamında **meşru savunma** hali söz konusudur.

Ancak, H, bu meşru savunma hakkını kullanırken sınırı aşmıştır. Yani icrası devam etmekte olan **hırsızlık suçunun işlenmesini** önlemek amacıyla ve **önlemeye yetecek ölçüde savunma hareketi** icra edebilir. Oysa H, bu ölçünün ötesine geçen bir hareket icra etmiştir. Bu itibarla H bakımından bir **hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşma** söz konusudur ve sorunu TCK'nın 27. maddesinin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde değerlendirmek gerekirdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararı, gerekçesinde neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçuna ilişkin olarak yer verilen değerlendirmeler bakımından da hatalıdır.

Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinden söz edebilmek için, **icrası tamamlanmış bir kasten yaralama suçunun** varlığı ve bu yaralama sonucunda kastedilen-

den ağır bir neticenin gerçekleşmesi (örneğin mağdurun ölmesi) gerekmektedir. Oysa, söz konusu olayda yaralama fiili meşru savunma hareketi olduğu için hukuka uygun kabul edilmeliydi. Ancak, olayda M öldüğü için, H hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dolayı verilecek cezada TCK, m. 27, f. 1’de belirtilen oranda indirim yapılması gerekirdi.

Bu karar göstermektedir ki, Yargıtay, mülga 765 s. TCK’nın 452. maddesi hükümleri çerçevesinde geliştirdiği hukukten tutarsız kararlarının etkisinden henüz kurtulamamıştır.

Bu eğilimin Yargıtay Dairelerinin yeni tarihli içtihatlarında da etkili olduğu gözlemlenmektedir:

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin **29.12.2011** tarihli ve E. 2011/3144, K. 2011/8592 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; bir gün önce gece saatlerinde kolluk tarafından icra edilen önleme araması faaliyeti sırasında alkollü olduğu tespit edilen ve bu sebeple hakkında idari para cezası verilmek, sürücü belgesine el konulmak, aracı bağlanmak suretiyle işlem yapılan M, ertesi gün sabah erken saatlerde elinde bıçakla hakkında işlem yapan kolluk görevlisi F’yi takip eder. Simitçiye simit almakta iken karşılaştığı F’yi elindeki bıçakla göğüs bölgesine vurarak yaralar. Bu saldırıya karşı kendisini korumaya çalışan F, aldığı bıçak darbeleriyle sağ ve sol ellerinden de yaralanır. F, yaralı vaziyette silahına davranması üzerine M kaçmaya başlar.

F, kaçmakta olan M’yi yakalamak amacıyla peşinden koşar; “dur” ihtarına ve havaya bir el ateş etmesine rağmen M kaçmaya devam eder. Bunun üzerine F, M’nin ayaklarını hedef alarak iki el daha ateş eder. Yaralı olan ve kan kaybetmesinin etkisiyle bitkin düşen F, kendinden geçerek yere yığılmak üzere iken dengesiz bir şekilde üçüncü atışı da yapar. M, bu atıştan çıkan mermi çekirdeğinin sırtından girmek ve göğüs bölgesinden çıkmak suretiyle yaralanması sonucu ölür.

İlk Derece Mahkemesi, bu olayda F hakkında kasten öldürme suçundan dolayı mahkumiyet hükmü kurmuştur.

Buna karşılık, Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise, “*hukuka uygunluk nedenlerinden Kanunun emrini yerine getirmede sınırın taksirle aşılması söz konusu olduğu*” gerekçesiyle, F’nin sırasıyla TCK, m. 85, f. 1; m. 27, f. 1 hükümleri uyarınca cezalandırılması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

⁸⁵⁵ Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin **1.7.2015** tarihli ve E. 2014/18098, K. 2015/12307 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; hakkında tutuklama kararı verilen ve kelepçesiz olan B, adliye çıkışında ailesi ile vedalaşırken, nezaretinde bulunduğu kolluk görevlilerinin bir anlık dalgınlığından istifade ederek hızla ara sokaklara doğru kaçmaya başlar. Kolluk görevlileri, yakalamak için arkasından B’nin akasından koşarlar. B, sözlü ikaza ve uyarı atışlarına rağmen durdurulamaz. Kolluk görevlilerinden S’nin 23 metrelik uzak atış mesafesinden yaptığı atışlardan çıkan mermi çekirdeklerinden biri, kaçmakta olan B’nin sol omuz bölgesini sıyrarak geçer; diğeri ise, kafasına isabet eder. B ölür. Daire kararında, S’nin bu atışları B’yi takip ederken düşüğü sırada yaptığı kabul edilir.

İlk derece Mahkemesi, bu olayda S’nin görevin yerine getirirken kullandığı yetkinin, kanun hükmünü icra hukuka uygunluk sebebinin **sınırını taksirle aştığını** kabul ederek, hakkında TCK, m. 85, f. 1 ve m. 27, f. 1 hükümlerine istinaden cezaya hükmetmiştir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise, bu olayda kaçan B’yi “*yakalamak için yaralama kastı ile hareket eden ve **sınırı kasten aştığı** hususunda duraksama yaşanmayan*” S’nin fiilinin TCK, m. 27, f. 1 “kapsamında değerlendirilemeyeceği”; ancak, “meydana gelen sonucu kabullenerek hareket ettiğine ilişkin kanıt bulunmadığından”, neticesi sebebiyle kasten yaralama suçundan dolayı, TCK, m. 87, f. 4 hükmü gereğince cezalandırılması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

Öncelikle belirtilmek gerekir ki, karara konu teşkil eden olayda, kaçan kişinin kimliği bellidir.

Hukuk, kimliği belli ve başka suretle yakalanması mümkün olan kişiye sırf kaçtığı, kaçmaya teşebbüs ettiği için silahla hedef ittihaz ederek ateş etmeye izin vermemektedir.

Buna karşılık, kaçan kişiyi yakalamak için korkutmak amacıyla hedef ittihaz etmeden havaya silahla ateş edilebilir. Bu itibarla, kolluk görevlilerinin elinden kaçan tutuklu kişiyi yakalamak amacıyla da olsa, hedef ittihaz ederek silahla ateş edilmesi fiili hukuka uygun değildir. Bu durumda TCK’nın hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılmasına ilişkin 27. maddesinin birinci fıkrası hükmünün uygulama kabiliyeti yoktur. Bu itibarla, Daire kararı doğrudur.

Ancak, olayda neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçunun oluştuğunu da kabul etmek imkanı bulunmamaktadır. Zira, hedef ittihaz edilerek bir kişiye silahla ateş

TCK'nın 27. maddesinin ikinci fıkrasında, meşru müdafaa sınıрын aşılmasına ilişkin özel bir hükme yer verilmiştir.⁸⁵⁶ 765 s. Kanunun sisteminde (m. 50) meşru müdafaa sınıрын aşılması genel olarak hukuka uygunluk nedenlerinde sınıрын aşılması kapsamında mütalaa edilmiştir.

Bir hukuka uygunluk sebebi olan meşru müdafaanın şartlarının esasen mevcut olmasına rağmen; saldırıya uğrayan kişi bu saldırıyı defedecek ölçünün üzerinde kuvvet kullanmış olabilir. Bu durumda, *savunmanın ölçüsünde sınıрын aşılması*^{857, 858} söz konusudur. Savunma amacıyla icra edilen fiil, saldırıya nazaran çok ağır olabilir.⁸⁵⁹

edilmesi halinde, kasten yaralama değil, **olası kastla öldürme** suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.

Şayet Daire kararında kabul edildiği gibi, S bu atışları B'yi takip ederken düştüğü sırada yapmış ise, sorunu TCK'nın **zorunluluk haline** ilişkin hükümleri (m. 25, f. 2) çerçevesinde değerlendirmek gerekirdi.

⁸⁵⁶ Doktrinde bazı yazarlar, bu hükmün uygulama alanının meşru savunma ile sınırlı tutulmasını ve zorunluluk halini kapsamına almamasını eleştirmektedirler (HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 228; TOROSLU/ERSOY, sh. 12). Dikkat edilmelidir ki, yeni TCK'nın sisteminde zorunluluk hali, bir kusurluluğu etkileyen neden olarak telakki edilmiştir. Bu bakımdan, somut olayda zorunluluk halinin koşulları bulunduğu takdirde, kişinin hukukun icaplarına göre davranma hususunda iradesini yönlendirme yeteneğinin tamamen ortadan kalktığı veya önemli ölçüde zayıfladığını kabul etmekteyiz. Dolayısıyla, Kanunda zorunluluk halinde sınıрын aşılmasına özgü bir hükme yer verilmesine gerek bulunmamaktadır. Halbuki meşru savunma kapsamında gerçekleştirilen fiille savunma sınırı heyecan, korku veya telaş dolayısıyla aşılmış olmasına rağmen, somut olayda yine de meşru savunma hali mevcuttur. Ancak, sınır aşılmıştır. Sınıрын aşılın kısmı itibarıyla fiil bir haksızlık oluşturmaktadır. Fakat, bu durumda kişiye, savunma sınırını aştığı kısmı itibarıyla fiili hukuka uygun olduğu için değil de, kişinin davranışlarının hukukun gereklerine göre yönlendirme yeteneği ortadan kalktığı için ceza verilmemektedir. Başka bir deyişle, bu durumda kişi hakkında beraat kararı değil, kusuru olmadığı için ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir (CMK, m. 223).

⁸⁵⁷ intensiver Notwehrzess.

⁸⁵⁸ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 842; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 248/249; TOROSLU, Zaruret Hali, sh. 161; ÖZEN, Muharrem: *Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa*, 1995, sh. 156. 1. CD, 14.6.1989, 1802/1921 (YKD, Ocak 1990, sh. 109); 1. CD., 17.9.1986, 2940/3019 (YKD, Kasım 1986, sh. 1706); 1. CD, 27.11.1984, 3718/4955 (YKD, Haziran 1985, sh. 884); 1. CD, 7.12.1982, 3068/4075 (YKD, Nisan 1983, sh. 603); 1. CD, 13.12.1982, 3377/4117 (YKD, Şubat 1983, sh. 263); ERSAN, Aykut: *Ceza Hukukunda Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınıрын Aşılması*, İstanbul 2013, sh. 63 vd.

⁸⁵⁹ Bu hususta bkz. DEMİRBAŞ, Timur: *Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınıрын Aşılması*, in: Hayri Domanic'e Armağan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını), İstanbul 1995, sh. 280; BAUMANN/WEBER/MITSCH, sh. 512; ROXIN, Lehrbuch(1), sh. 636 vd; JAKOBS, Lehrbuch(1), sh. 482 vd; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 442 vd.; ÖZAYDIN, sh. 117 vd., 244 vd.

Doktrinde, henüz bir saldırıda bulunulmamış veya saldırı sona ermiş olmasına rağmen, kişinin kendisini savunmak amacıyla hareket etmiş olması halinde; *meşru müdafaa zaman itibarıyla sınıрын aşılmış* olduğu (extensiver Notwehrzess) kabul edilmektedir. Ancak, bu konudaki görüşler arasında birlik mevcut değildir. Bazı yazarlar; sadece saldırı sona ermiş olmasına rağmen, kişinin kendisini savunma amacıyla hareket etmiş olması halinde; sınır aşılmasına ilişkin hükmün (Alman CK, § 33) tatbik kabiliyeti bulabileceğini ve dolayısıyla, faile ceza verilmeyeceğini kabul etmektedirler (BAUMANN/WEBER/MITSCH, sh. 513; JAKOBS, Lehr-

27. maddenin ikinci fıkrasına göre, meşru müdafaada sınırın aşılmasının içine düşülen “*heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş*” olması halinde, kişiden hukukun icaplarına uygun davranması beklenemez⁸⁶⁰. Maruz kaldığı saldırı karşısında kişinin içine düştüğü **korku, telâş** veya **şaşkınlık** dolayısıyla davranışlarını yönlendirebilme yeteneği artık ortadan kalkmıştır. Bu itibarla; söz konusu hallerde meşru müdafaanın sınırının aşılmış olmasından dolayı fail kusurlu telâkki edilemez⁸⁶¹. Ancak fıkra metninde, bu hükmün mehzazını oluşturan Alman CK, § 33 hükmünden farklı olarak, “*mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaş*” ibaresine yer verilmiştir. Aslında saldırı karşısında kişinin içine düştüğü heyecan korku veya telaşın mazur görülebilecek nitelikte olup olmadığını ayrıca araştırmaya gerek yoktur. Kişi maruz kaldığı saldırı karşısında içine düştüğü “*heyecan, korku veya telaş*” her zaman mazur görülebilecek niteliktedir. Bu nedenle, fıkra metninde yer alan “*mazur görülebilecek*” ibaresinin sadece açıklayıcı bir fonksiyonunun olduğunu düşünmek gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü, maruz kaldığı saldırı karşısında içine düştüğü “*heyecan, korku veya telaştan*” dolayısı meşru savunma sınırını aşan kişi, davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirme yeteneği ortadan kalktığı için, kusurlu addedilmemektedir. Baş-

buch(1), sh. 483/484; DEMİRBAŞ, Domaniç’e Armağan, sh. 280. Bazı yazarlar ise, henüz saldırıda bulunulmamış olmasına rağmen, kişinin kendisini savunmak amacıyla hareket etmiş olması halinde dahi, meşru müdafaanın zaman itibarıyla sınırının aşılmış olduğunu ve dolayısıyla, faile (Alman CK, § 33 hükmüne istinaden) ceza verilmeyeceğini kabul etmektedirler (ROXIN, Lehrbuch[1], sh. 637; SPENDEL, LK[10], § 33, kn. 8; LENCKNER, Schöнке/Schröder[23], § 33, kn. 7).

Alman doktrininde taraftar bulan bir görüşe göre; meşru müdafaada sınırın aşılması halinde faile ceza verilmeyeceğine ilişkin Alman Ceza Kanunu’ndaki hükmün sadece *savunmanın ölçüsünde sınırın aşılması* halinde tatbik kabiliyeti yoktur (JESCHECK, Lehrbuch[4], 444; MAURACH/ZIPF I, sh. 451; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 448).

Bizim kanaatimize göre; henüz bir saldırıda bulunulmamış veya saldırı sona ermiş olmasına rağmen, kişinin kendisini savunmak amacıyla hareket etmiş olması halinde; bir sınır aşılmasından bahsedilemez. **Sınırın aşılmış olmasından bahsedebilmek için, meşru müdafaanın şartlarının esasen mevcut olması gerekir.** Halbuki bahsi geçen durumda saldırının halen var olması şartının (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 807) gerçekleşmiş olduğundan bahsedilemez. Bu durumda ancak meşru müdafaanın şartlarında yanılgiya ilişkin hükümler (TCK, m. 30, f. 3) uygulama kabiliyeti bulabilir (aynı mealde MAURACH/ZIPF I, sh. 451).

⁸⁶⁰ JAKOBS, Lehrbuch(1), sh. 482.

⁸⁶¹ DEMİRBAŞ, Domaniç’e Armağan, sh. 281; BAUMANN/WEBER/MITSCH, sh. 511/512; BOCKEMLANN/VOLK, 130. *Önder*, bu durumda kişinin “kusur yeteneğine sahip olamayacağı” ve hatta, “kasten” hareket edemeyeceği fikrindedir (ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 246, 247). Bu durumda bir “mücbir sebep”in varlığını kabul eden fikir için bkz. DÖNMEZER/ERMAN II, no. 839.

Ancak, bu durumda bir *mazeret sebebinin* varlığını kabul eden yazarlardan bazıları, yukarıda da izah edildiği gibi, işlenen fiilin hem haksızlık muhtevasının hem de kusur muhtevasının azalmış olduğunu kabul etmektedirler (Bkz. JESCHECK, Lehrbuch[4], sh. 443). Bir diğer görüş ise; bu durumda bir *şahsi cezasızlık sebebinin* mevcut olduğunu kabul etmektedir (Bkz. JAKOBS, Studien, sh. 145/146).

ka bir deyişle, bu “*heyecan, korku veya telaş*”, kişi açısından somut olayda bir *mazeret sebebi* oluşturmaktadır.^{862,863,864}

⁸⁶² Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN, *Uygulamalı Ceza Hukuku*, sh. 277 vd.; KOCA, *Ceza Hukuku Dergisi*, Ekim 2006, sh. 141 vd.; ŞAHİN, *Cumhur/ÖZGENÇ, İz-zet/KILIÇ*, Ali Şahin: “*Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması*”, in: Prof. Dr. Rıza Ayhan’a Armağan, cilt II, Ankara, Haziran 2022, sh. 2301 vd.

⁸⁶³ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 31.3.2009 tarihli ve E. 2008/1-201, K. 2009/81 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; 6.9.2005 günü saat 13.30 sıralarında “*yasadışı terör örgütü sem-patizanı olan*” yaklaşık 150-200 kişilik bir grup basın açıklaması yapmak için toplanırlar. Ba-sın açıklaması yapıldıktan sonra grup içerisinde terör örgütü lehine “*Kürdistan faşizme me-zar olacak*”, “*Burası Kürdistan, Türkiye değil*”, “*Biji serok APO*”, “*PKK halktır halk burada*” ve benzeri ifadelerle sloganlar atılır. Grup takiler, kolluk tarafından yapılan dağılma uyarılarına uymayarak, taş ve sopalarla işyerlerine, araçlara ve kolluk görevlilerine saldırırlar; kamuya ve özel kişilere ait birçok iş yerinin ve araçların camlarını kırarlar.

Bu sırada, görev gereği olarak ve başka bir iş için olay yerinden geçmekte olan asker GY’nin yönetimindeki aracın camları tamamen kırılır, araçta maddi hasar meydana gelir ve ayrıca, GY ile birlikte araçta bulunan iki asker çeşitli yerlerinden yaralanır. Araç içinde bulunan üç asker, bu saldırılar ve göstericilerin aracı sallamaya başlamaları karşısında, korku ve heyecana kapılırlar. Bu durum karşısında GY elindeki otomatik silahla “*seride bir kez*” ateş eder. Bu-nun üzerine GY ve beraberindekiler, ortalığın nispeten sakinleşmesinden yararlanarak araçla olay yerinden uzaklaşırlar. Ancak, GY’nin silahından çıkan kurşunlardan biri göstericilerden A’nın kafasına isabet ederek ölümüne sebebiyet verir.

CGK’nın kararına göre; bu “olayda, maktûlün de içinde bulunduğu kalabalık tarafından vücut bütünlü-ğüne yönelik saldırısı karşısında, sanığın kendisini ve yanında bulunan jandarma erlerini savunma hak-kının doğduğu kabul edilmelidir. Ancak, sanığın saldırgan kişileri yaralamaya yönelik olarak, örneğin bacaklarına doğru ateş ederek saldırıyı defetmesi olanaklı iken ölenin de bulunduğu kalabalığa doğru şahıs ve hedef gözetmeksizin makineli tabancasıyla seride rasgele ateş etmesi sonucu maktûlü başından vurarak öldürmesi eyleminde, saldırı ve savunmaya ilişkin diğer koşulların bulunduğu kuşku bulunmamakta ise de, “*gerçekleştirilen savunmanın, maruz kalınan tecavüzü defedecek ölçüde olması*” yani “*saldırı ile savunma arasında oran bulunması*” koşulu gerçekleşmediğinden yasal savunmanın ko-şullarının oluştuğundan söz edilemez. Bir başka anlatımla, savunma ile saldırı arasındaki denge savun-ma lehine tartışmasız biçimde bozulmuş, dolayısıyla da ölçülülük ya da orantılılık ilkesi ihlal edilmiştir.

Savunmanın, yasal savunma koşullarında başladığı, ancak orantılılık ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle yasal savunmanın gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğine göre bu durumda, TCY’nın 27. maddesinde düzenlenen “*sınırın aşılması*”nın söz konusu olup olamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir. Sanığın, herhangi bir hedef gözetmeden kalabalıktaki kişi-lerin üzerine rasgele ateş ettiği ve sınırın kastla aşıldığı sabit olduğuna göre, maddenin 1. fık-rasının olayda uygulanma koşullarının bulunmadığı açıktır.

Yasa koyucu tarafından sadece yasal savunmaya ilişkin olarak kabul edilen ve anılan madde-nin 2. fıkrasında düzenlenen *mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelen nedenlerle sınırın aşılmasının* olayda uygulanmasının söz konusu olup olamayacağına gelin-ce; uzun yıllardır yaygın terör olaylarının yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Siirt İlinde gerçekleşen yargılama konusu olayda sanığın ve yanında bulunan iki jandarma erinin maruz kaldığı ve ölüme yönelik sözlerle de desteklenen fiili saldırının ağırlığı, uyarılara karşın ısrarla ve artarak devam etmesi ile bölgenin özellikleri bir bütün olarak göz önüne alın-dığında **yasal savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş ile aşıldığı**nın kabulü zorunludur. Sanığın yaşanan olayın etkisiyle içine düştüğü psikolojik hal nedeniyle heyecanlanması, paniğe kapılması ve hatta korkması bunun sonucunda da yasal sa-vunma sınırını aşması beklenebilecek bir durum olup, somut olayda TCY’nın 27. maddesinin 2. fıkrasının uygulanma koşulları gerçekleşmiştir.

Şayet sınır öfke ve gazap gibi sebeplerle aşılmış ise, mesele genel tahrik kural-larına göre çözümlenmelidir.^{865,866}

Bu itibarla, sanığın olayda yasal savunma sınırını mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaş ile aştığını kabul ederek TCY'nın 27. maddesinin 2. fıkrası ile 5271 sayılı CYY'nın 223. maddesinin 3. fıkrasının c bendi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar veren yerel mahkeme ile bu kararı onayan Özel Daire çoğunluk görüşünde bir isabetsizlik olmayıp Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.”

Ancak, oyçokluğu ile alınan bu kararda, çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Üyeleri, “*itirazın kabulü ile sanığın yasal savunma sınırını taksirle aşması nedeniyle hakkında TCY'nın 27/1. maddesinin yollamasıyla TCY'nın 85/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği*” düşüncesiyle, karşı oy kullanmışlardır.

⁸⁶⁴ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 1.3.2016 tarihli ve E. 2015/1-1039, K. 2016/96 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda müteahhitlik yapan E ile M ve ailesi arasında bir hukuki ihtilaf bulunur. Taraflar sorunu halledebilmek için birkaç kez görüşürler. Ancak bir çözüme ulaşamazlar. Son görüşmelerinden bir iki gün sonra, M'nin oğlu C, E'ye telefon ederek arsa yerine satış bedelini ödemeleri durumunda anlaşılabileceklerini söyler. Bunun üzerine E, fiyat araştırması yaptırır ve C'yi telefonla arayarak, emsal arsa fiyatının metrekare başına 400 ilâ 450 TL olduğunu belirtir. Bu cevabı beğenmeyen C, “siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, emsal arsaların metrekare fiyatı 1.000 ilâ 1.300 TL, ben böyle işi sinkaf ederim, erkeksen yarın işyerinde olursun en fazla on sene yatarım” diyerek telefonu kapatır. Olay günü M, yanına oğulları S, C ve Ç'yi alarak, E ve ailesine ait müteahhitlik bürosuna gitmek için yola çıkarlar. M ve oğlu S, tabancalarını yanlarına alırlar. Geldikleri aracı park ettikten sonra, E'nin kardeşi K ve diğer bir kişi Z ile birlikte büronun önünde konuştukları sırada olay yerine gelirler. Bu sırada aralarında kavga çıkar. Kavga sırasında M, E'yi omzundan tutarak kendine doğru çeker ve belinden çıkardığı tabancasını E'ye doğrultur ve iki el ateş eder. E, yaralanır. Bu esnada M'nin oğulları S ve C de E'nin kardeşi K'ye saldırarak darp ederler. M, bu kez oğulları C ve S tarafından yere düşürülerek darp edilen K'ye ateş eder ve K yaralanır. **E, M'nin kendisine ve kardeşi K'ye yönelen bu silahlı saldırısını defetmek maksadıyla rastgele silahla mütead-dit el ateş eder.** Bu atışlardan isabet alan M ölür, oğulları C ve S ise yaralanır.

Ceza Genel Kurulu, bu olayda E'nin meşru müdafaada halinde olduğunu ve fakat, içine düştüğü korku telaş ve panik sebebiyle, meşru müdafaanın sınırını aştığını (TCK, m. 27, f. 2) kabul etmiştir.

⁸⁶⁵ JAKOBS, Lehrbuch(1), sh. 483; CGK., 3.6.1985, 185/331 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 670 vd. [674]).

⁸⁶⁶ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 5.10.2010 tarihli ve E. 2010/1-170, K. 2010/182 sayılı Kararında **meşru müdafaada sınırın aşılması** ile ilgili olarak yer verilen şu açıklamalar, önem taşımaktadır:

“Somut olayda saldırının tekrarlanabileceği kabul edildiği takdirde, saldırı ve savunmaya ilişkin diğer koşulların bulunduğu kabul edilebilir ise de, “**gerçekleştirilen savunma, maruz kalınan tecavüzü defedecek ölçüde olması**” yani “**saldırı ile savunma arasında oran bulunması**” koşulu gerçekleşmediğinden yasal savunma koşullarının oluştuğundan bahsedilemez. Zira, **maktûlün, kendisinin ve arkadaşının vücut dokunulmazlığına yönelik saldırısı karşısında, sanığın savunma hakkının doğduğunun kabulü olanaklı ise de; sanığın maktûlün elinde bulunan bıçağı aldıktan sonra silahsız ve bir anlamda savunmasız kaldığı anlaşılan maktûl ve mağdurlara bıçakla vurması eyleminde**, savunma ile saldırı arasındaki dengenin savunma lehine bozulmuş olduğu, dolayısıyla da ölçülülük ilkesinin ihlal edilmiş olması nedenine dayalı olarak **yasal savunma koşullarının oluşmadığı** kabul edilmelidir.

Savunmanın yasal savunma koşullarında başladığı, fakat ölçülülük ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle yasal savunmanın kabul edilmediği bu gibi durumlarda, “sınırın aşılması” söz konusu olabilmektedir.

“Sınırın aşılması” da 5237 sayılı TCY'nın 27. maddesinde “**ceza sorumluluğunu etkileyen nedenlerden biri**” olarak düzenlenmiştir.

...

Hukuka uygunluk nedeninin bulunması, eylemin suç olmasını engelleyeceğinden, bu durumda fail hakkında 5271 sayılı CYY'nın 223/2-d bendi uyarınca beraat kararı verilmesi gerekecektir. Buna karşılık, "sınırın aşılması" bir hukuka uygunluk nedeni değil, **27. maddenin 1. fıkrasındaki durum itibarıyla kusurluluğu azaltan, 27. maddenin 2. fıkrasındaki durum itibarıyla da kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerden birisi** olduğundan, hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, Yasanın 27/1. maddesine göre indirimli ceza veya Yasanın 27/2. maddesine göre 5271 sayılı CYY'nın 223/3-c bendi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmelidir.

Şu halde, 27. maddenin 1. fıkrasının uygulanabilmesi için; öncelikle bir hukuka uygunluk nedeninin söz konusu olması ve failin, bu hukuka uygunluk nedenine ilişkin koşulların sınırlarını "kast olmaksızın" aşması gerekmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da sınır kasten aşılmış ise bu fıkra ile uygulama yapılamayacaktır.

Somut olayda; sınırı kasten aştığı hususunda duraksama yaşanmayan sanığın eyleminin 5237 sayılı TCY'nın 27/1. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır.

Sanığın eyleminin 5237 sayılı Yasanın 27/2. maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine gelince;

5237 sayılı Yasanın 27/2. maddesinin uygulanabilmesi için;

- 1- Yasal savunma kapsamında korunabilecek bir hakkın bulunması,
 - 2- Saldırıya ilişkin koşulların gerçekleşmesi,
 - 3- Savunmaya ilişkin koşullardan "ölçülülük" şartının, savunma lehine ihlal edilmesi suretiyle sınırın aşılması,
 - 4- "Sınırın aşılmasının" mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi,
- gerekmekte olup, bu koşulların birlikte gerçekleşmesi halinde, yasal savunmada sınırı aşan faile ceza verilmeyecektir.

Bu durumda; **kişinin, maruz kaldığı saldırı karşısında içine düştüğü korku, telaş ve şaşkınlık dolayısıyla davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalkması** söz konusu olacağından, yasal savunmada sınırın aşılmasından dolayı **kusurlu sayılmayacağı** kabul edilir. Dolayısıyla burada belirleyici olan, maruz kalınan saldırının kişiyi içine düşürdüğü psikolojik durumdur. Zira, **kişi** **sırf maruz kaldığı saldırının tesiriyle, "heyecan, korku ve paniğe" kapılarak yasal savunmanın sınırlarını aştığında** bu maddeden yararlanabilecek, buna karşılık; **sırf saldırının etkisiyle değil de, (velev ki saldırıdan kaynaklanmış olsa dahi) öfke ve gazap gibi nedenlerle sınırı aştığında ise aynı korumadan faydalanamayacaktır.** Başka bir deyişle, sınırın aşılması konusunda failin o anda içinde bulunduğu ruh hali gözönünde tutulacaktır. Yani, failin niyeti, failin icra tarzına ve ruh haline göre ciddi bir saldırının def'inden ziyade, kin duygusunu tatmine yönelik ise "yasal savunmanın" sınırlarını aşma değil, ancak haksız tahrik söz konusu olabilecektir.

Somut olayda; maktûl ve mağdurlar öncelikle Ersin'in vücut bütünlüğüne yönelik bir saldırıda bulunmuşlar, Ersin'in bağırarak yardım istemesi nedeniyle sanık Fatih'in olay yerine gelmesi üzerine de, bu saldırıyı "Fatih'e" yöneltmişlerdir. Sanık Fatih'e yönelik saldırı, maktûl tarafından "bıçakla", mağdurlar tarafından ise "taşlar ve mermer parçaları ile" yapılmıştır. Burada maktûl ile mağdurlardan gelen ve "sanığın yaşam hakkına veya en azından vücut dokunulmazlığına" yönelen haksız bir saldırı bulunmakta ve devam etmekte ise de; sanık Fatih'in girdiği mücadele sonunda Ayhan'ın **elindeki bıçağı almasının ardından**, maktûl ve mağdurların **saldırıları durmuş**, fakat sanık olaydan kaynaklanmış bile olsa arkadaşının yaralanmasından duyduğu üzüntünün ve kendisine karşı yapılmış ve **bitmiş olan saldırının** kızgınlığı ile maktûl ile mağdurları bıçakla yaralamış, eline geçirdiği bıçakla maktûlün önce sağ karın kısmına vurarak karaciğer sağ alt lobunu, bununla da yetinmeyerek bıçağı yukarı doğru hareket ettirerek sağ diyaframayı parçalayarak, ölüme neden olmuştur. Bu şekilde gerçekleşen olayda üzüntü ve kızgınlığın etkili olduğu, dolayısıyla, ağır düzeydeki **haksız tahrik altında işlen-**

Meşru savunma ile haksız tahrik arasındaki en önemli fark, failin **saldırısı etkisiz kılmak amacıyla** hareket etmesidir. Saldırısı etkisiz kılma amacının yanı sıra öfke ile de hareket edilebilir. Savunma amacının yanı sıra öfke ve hiddetle hareket etmek, savunmada ölçüsüz davranılması ve sınırın aşılması sonucunu doğurabilir.

Örneğin çelimsiz bir kişinin gücü kuvveti yerinde bulunan diğer bir kişiye karşı fiili saldırısı, bazı durumlarda bu kişide heyecan, korku veya telaş meydana getirmeyebilir. Gücü kuvveti yerinde olan kişi, çelimsiz kişinin saldırısını bu kişiye karşı kasten yaralama suçunu oluşturmayacak şekilde zor kullanarak, elini kolunu tutarak engelleyebilir. Bu gibi durumlarda, gücü kuvveti yerinde olan kişi, çelimsiz kişinin saldırısının kendisinde oluşturduğu öfkeyle, bu saldırısı etkisiz kılacak ölçünün dışına çıkarak bu kişiye karşı cebir kullandığı takdirde, artık meşru savunmanın varlığından söz edilemez. Aksine, bu gibi durumlarda kusurluluğu etkileyen haksız tahrik hali söz konusu olur.

Bu bakımdan TCK, m. 129 hükümleri önemli bir örnek teşkil etmektedir: Maruz kalan haksız fiile, mesela kasten yaralamaya tepki olarak hakarete bulunulması halinde, saldırısı etkisiz kılma, savunma amacından söz edilemez. Bu gibi durumlarda kusurluluğu etkileyen ve hatta ortadan kaldıran haksız tahrik hali söz konusudur⁸⁶⁷.

Ancak, örneğin gücü kuvveti yerinde bulunan bir kişinin çelimsiz diğer bir kişiye karşı fiili saldırısı, kuşkusuz bu kişide korku, telaş ve heyecan meydana getirir. Gücü kuvveti yerinde olan kişinin bu saldırısını etkisiz kılmak amacıyla, çelimsiz kişi sa-

miş kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından bahsedilebilirse de, mazur görülebilecek bir korku, panik ya da heyecanın tesirinden söz edilemeyeceğinden, 5237 sayılı TCY'nın 27. maddesinin 2. fıkrasının uygulanma koşullarının oluştuğu söylenemez."

Bu konuda ayrıca bkz. CGK, **10.12.2013**, E. 2013/1-60, K. 2013/603; CGK, **28.5.2013**, E. 2012/1-1286, K. 2013/264.

⁸⁶⁷ Nitekim Yargıtay uygulaması, öldürülenin taşkınlıkları karşısında asker kişinin öldürme fiilinin, meşru savunmada sınırın aşılması çerçevesinde değil, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi yönündedir:

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin **15.6.2010** tarihli ve E. 2009/5332, K. 2010/4528 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; askerlik görevi yapan Sedat ve Coşkun, birlikte nöbet yerinden karakola dönerken, aldıkları ihbar bilgisi üzerine askeri yasak bölge içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu yere intikal ederler. Bu sırada, kaçak göçmenlerin sınırdan geçmesine aracılık eden Yusuf, askerlerle birlikte olay yerine gelerek askerlere yer gösteren Umut'a saldırmaya çalışır. Bunun üzerine Sedat, Yusuf'a tokat atar ve Yusuf ile Sedat birbirleriyle boğuşmaya başlarlar. Bu boğuşma sırasında, Sedat görev gereği taşıdığı tüfeğin kasaturası ile Yusuf'u yaralar. Yusuf, **sağ göğüs üst bölgesinden aldığı iki yara** sonucu ölür. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun raporuna göre, her iki yara da **yukarıdan aşağı seyirlidir**.

İlk Derece Mahkemesi, bu olayda, Sedat'ın meşru savunma halinde bulunduğunu ve fakat maruz kaldığı saldırının oluşturduğu heyecan, korku ve telaşın etkisiyle savunmada sınırı aştığını kabul ederek, hakkında TCK, m. 27, f. 2 ve CMK, m. 223, f. 2, bent c hükümlerine istinaden **ceza verilmesine yer olmadığı kararı** vermiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise, bu olayda Sedat'ın **haksız tahrik** etkisinde kalarak **kasten öldürme** suçunu işlediği yönünde içtihatla bulunmuştur.

vunma hareketleri gerçekleştirirken, ölçüyü kaçırmış olabilir. İşte bu gibi durumlarda, TCK'nın 27. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulama kabiliyeti bulur.

Ancak, TCK, m. 27, f. 2 hükmünün mehzazını oluşturan Alman CK, § 33 düzenlemesinde yer almamasına rağmen, söz konusu fıkra hükmünde “heyecan, korku veya telaş” ibaresinden önce ayrıca “*mazur görülebilecek*” ibaresine yer verilmiş olması karşısında, maruz kaldığı saldırı devam ederken, bu saldırının etkisi altında iken kişinin yaşadığı korkunun, heyecan ve telaş halinin, kusurluluğunu ve dolayısıyla, ceza sorumluluğunu tamamen ortadan kaldıracak boyutta olup olmadığı tartışılabilir. Ex ante yapılan değerlendirmede, saldırıya maruz kalan kişinin yaşadığı korku, heyecan ve telaş hali mazur görülebilecek yani kusurluluğunu tamamen ortadan kaldıracak boyutta görülmediği takdirde, sorun TCK, m. 27, f. 1 hükümleri çerçevesinde ele alınabilir.

Dikkat edilmelidir ki; 27. madde kapsamında sözü edilen sınırın aşılması halinde bir yanılma söz konusu değildir. Hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında yanılma haline ilişkin çözüm şekli, yeni TCK'nın 30'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir.

Kişi, maruz kaldığı saldırı karşısında kendisini savunmak için saldırganı karşı gerçekleştirdiği fiille, bir üçüncü şahsın ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda, sorunun zorunluluk hali hükümleri çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz⁸⁶⁸.

İ. Haksız Tahrik

Yeni TCK'nın 29. maddesi, kişiye haksız fiilin kendisinde oluşturduğu hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlediği suçtan dolayı verilecek olan cezanın belli bir oranda indirilmesini öngörmüştür.

765 s. Kanundan farklı olarak, yeni TCK'da, bütün suçlar açısından geçerli olan genel haksız tahrik hükmünün yanı sıra, belli suçların bir haksız fiilin oluşturduğu gazap veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmesi halinde bu suçların cezasında belli bir oranda indirim yapılması gerektiği yönünde hükümlere yer verilmemiştir⁸⁶⁹.

Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği **hiddetin** (öfkenin, gazabın) etkisi altında bir suç işlemesi halinde **kusur yeteneğindeki**

⁸⁶⁸ ŞAHİN/ÖZGENÇ/KILIÇ, Rıza Ayhan'a Armağan, sh. 2315.

⁸⁶⁹ Ceza Kanununda genel anlamda kusur yeteneği üzerinde bir etkisi olması itibarıyla haksız tahrik kusurluluğu azaltan bir sebep olarak kabul edilmiş olmasına rağmen; bazı özel hükümlerde haksız tahrik nedeniyle failin cezasında indirim yapılacağı özellikle ifade edilmiştir. Türk ceza hukuku doktrinde bu özel hükümlerle ilgili olarak “*özel haksız tahrik halleri*”nden söz edilmektedir. Bu konuda 765 s. TCK'nın şu hükümleri örnek olarak gösterilebilir: Memura karşı hakaret veya sövmenin, memurun memuriyet sınırını aşması veya keyfi hareketleri sonucu olması haline ilişkin olarak, m. 272; hakaret veya sövmenin, mağdurun kendi haksız hareketinin sonucu olması haline ilişkin olarak, m. 485; zina halinde yakalama haline ilişkin olarak, m. 462.

azalmayı ifade etmektedir. Haksız tahrik, kusurun irade unsuru üzerinde etkili olan bir nedendir. Haksız tahrik halinde **failin iradesinde** bir **zayıflama** meydana gelmektedir⁸⁷⁰. Böylece, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altındaki kişinin suç işlemekten kendisini alıkoyma yeteneği, önemli ölçüde azalmış bulunmaktadır. Böyle bir etki altında kalan kişinin, kendini yönlendirme veya belli fiilleri işlemekten alıkoyma yeteneğinin tam olduğundan bahsedilemez. Ancak, hiddetin kusur yeteneğini zayıflatın bir etkisini kabul edebilmek için, bunun **haksız bir fiilden** kaynaklanması gerekir⁸⁷¹.

Haksız tahrik halinde fiilin haksızlık muhtevassından bir azalma söz konusu değildir; burada söz konusu olan, sadece kusur muhtevassında bir azalmanın meydana gelmesidir⁸⁷². Bu nedenle haksız tahrikin soyut bir şekilde bir “hafifletici sebep” olarak öngörülmesi⁸⁷³ doğru değildir^{874, 875}.

⁸⁷⁰ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 375/376; DEMİRBAŞ, Timur, Türk Ceza Kanununda Özel Haksız Tahrik Halleri, İstanbul, 1985, sh. 35; KANGAL, Zeynel T.: *Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik*, in: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XIV, sayı 3-4, Aralık 2010, sh. 31.

⁸⁷¹ “**Ceza sorumluluğunu azaltan bir neden** olarak düzenlenen haksız tahrik; kişinin haksız bir fiilin kendisinde oluşturduğu hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi durumunda **kusur yeteneğindeki azalmayı** ifade etmektedir. Bu halde fail, suç işleme yönünde önceden bir karar vermeksizin, dışarıdan gelen etkinin ruhsal yapısında meydana getirdiği karışıklığın bir sonucu olarak suç işlemeye yönelmektedir. Bu yönüyle haksız tahrik, **kusurun irade unsuru üzerinde etkili olan bir nedendir**. Başka bir anlatımla, haksız tahrik halinde failin **iradesi üzerinde bir zayıflama** meydana gelmekte, böylece haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındaki **kişinin suç işlemekten kendisini alıkoyma yeteneği önemli ölçüde azalmış bulunmaktadır**.”: CGK, **18.11.2014**, E. 2014/1-146, K. 2014/494. Ayrıca bkz. CGK, **5.4.2016**, E. 2015/1-532, K. 2016/172; CGK, **1.3.2016**, E. 2015/1-848, K. 2016/105; CGK, **28.6.2011**, E. 2011/1-99, K. 2011/145; CGK, **23.3.2010**, 2009/1-221, 2010/61, CGK, **13.10.2009**, 2009/1-141, 2009/229.

⁸⁷² ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku(2), sh. 128/129, 205; Anayasa Mahkemesi, 25.5.2022, BB. 2019/33136, pn. 110 ilâ 112.

⁸⁷³ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1087; TCK Hükümet Tasarısı m. 31 gerekçesi; ‘89 Öntasarısı, m. 32 gerekçesi; ‘97 Öntasarısı, m. 32 gerekçesi.

⁸⁷⁴ DEMİRBAŞ, Haksız Tahrik, sh. 35.

⁸⁷⁵ Haksız tahrikin kusurluluğu etkileyen bir sebep olması dolayısıyla, **iştirak halinde işlenen suçlarda, sadece haksız tahrikin etkisi altında hareket eden suç ortağının cezasında bu sebeple indirim yapılması ve diğer suç ortaklarının cezasında bu sebeple indirim yapılmaması gerektiği** hususunda açıklamaların yer aldığı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **15.11.2011** tarihli ve E. 2011/1-123, K. 2011/229 sayılı Kararı, önem arz etmektedir:

“Haksız tahrik, haksız bir fiilden etkilenen failin ruhsal durumundan dolayı **kusurunun azaldığı** görüşüne dayanmaktadır. Buna göre, **yalnızca şahsında bu koşullar gerçekleşen fail bakımından uygulanabilir**. Başka bir deyişle haksız tahrik, kusuru azaltan kişisel bir nedendir. Haksız tahrikin suça iştirak edenlere (müşterek fail veya diğer şeriklere) de uygulanabilmesi için, tahrike ilişkin koşulların tüm şerikler hakkında geçerli olması zorunludur. Bu nedenle **müşterek fail veya iştirak edenlerden bir kısmı hakkında tahrik koşulları gerçekleşmiş, diğerleri hakkında gerçekleşmemiş ise, 29. madde yalnızca haksız tahrik koşulları gerçekleşen kişiler hakkında uygulanabilecektir**.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Sanık Yasemin Tek ile cinsel ilişkiye girdiğini arkadaşlarına anlatarak halk arasında söylenmeye neden olan maktul Sedat Genç’in, sanık Yasemin ile aralarındaki ilişkiyi açığa çıkarma

Kanun, haksız tahrik halinde **cezada sadece indirim** yapılmasını öngördüğü için, hiddetin etkisindeki kişinin kendisini suç işlemekten alıkoyma yeteneğini tamamen kaybedebileceği kanunen kabul edilmemiş olmaktadır.^{876, 877}

şeklindeki davranışının sadece sanık Yasemin bakımından haksız tahrik oluşturduğu, Yasemin ile akrabalık bağı dahi bulunmayan sanıklar Selçuk Ertuğral ve Ali Güngör yönünden haksız tahrik oluşturmadığı gibi, somut olayda sanıklar Selçuk ve Ali'ye yönelik olarak maktulden kaynaklanan başkaca haksız hareketin de bulunmadığı gözetildiğinde, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına karar veren yerel mahkemenin direnme hükmü usul ve yasaya aykırıdır.” Ayrıca bkz. CGK, 5.2.2013, E. 2012/1-1416, K. 2013/41.

⁸⁷⁶ Uygulamada, haksız tahrikin varlığı halinde, özellikle kasten öldürme suçu bakımından cezada yapılacak olan indirimin üst sınırı itibarıyla rahatsızlık duyulduğu gözlemlenmektedir. Örneğin müebbet hapis cezasını gerektiren kasten öldürme suçunun maruz kalınan haksız bir fiil olarak hakaretin oluşturduğu öfkenin etkisiyle işlenmesi halinde, faile verilebilecek en yüksek ceza 18 yıl hapis cezası olabilmektedir. Bu mülahazayla TCK’nın 29. maddesinin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu itirazı reddetmiştir (19.2.2009, E. 2007/91, K. 2009/25. RG: 2 Haziran 2009/27246).

⁸⁷⁷ Ancak, Kanunun “*Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret*” başlıklı 129’uncu maddesinde, haksız tahrik olgusunun bazı durumlarda kişinin hukukun icaplarına göre davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracabileceği kabul edilmektedir:

“Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” (birinci fıkra).

“Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi hâlinde, kişiye ceza verilmez.” (ikinci fıkra).

“Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” (üçüncü fıkra).

Dikkat edilmelidir ki, genel haksız tahrikten farklı olarak, 129. maddedeki özel haksız tahrik hükmünün uygulanabilmesi için; hakaret suçunun, kendisine karşı kasten yaralama suçu işlenen, kendisine hakaret edilen veya kendisine karşı sair bir haksız fiil işlenen kişi tarafından işlenmesi gerekir. Nitekim, söz konusu madde gerekçesinde, ikinci fıkra hükmüyle bağlantılı olarak, *“kişi kendisine karşı işlenen kasten yaralama suçuna tepki olarak işlediği hakaret suçu dolayısıyla cezalandırılmayacaktır.”* açıklamasına yer verilmiştir. (Bu bakımdan, doktrinde ileri sürülen, söz konusu 129. maddenin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için, hakaret suçunun kasten yaralama suçunun mağduru tarafından işlenmesinin şart olmadığı yönündeki açıklamalar (TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat: *Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku*, 5. bası, Ankara, 2007, sh. 442), mesnetsizdir.

Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**’nun 18.03.2008 tarihli ve E. 2007/4.MD.115, K. 2008/53 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda:

... Vergi Mahkemesi üyelerinden birinin başka göreve atanması sebebiyle, bu üyenin takip ettiği dosyalar, Mahkeme Başkanı MCD tarafından dağıtılır ve bir kısmı diğer Üye SK’ya verilir. Üye SK, mahkeme kaleminde **“başkasının s...b...u ben mi temizleyeceğim”** biçiminde sözlerle bu dağıtıma tepki gösterir. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı MCD, bir yazı yazarak Üye SK’yı uyarır. Üye SK, Başkanın odasına giderek **“bana uyarı yazısı yazamazsınız”** deyip **yazıyı yırtmak suretiyle tepki** gösterir. Başkan MCD ise kendisine **“saygısızlık yapıyorsun, şerefsizlik yapma”** sözleriyle karşılık verir. Üye SK da MCD’ye **“şerefsiz sizsiniz”** biçiminde mukabelede bulunur.

Bu olay nedeniyle Başkan MCD ve Üye SK hakkında “görevde hakaret suçu”nu işlediklerinden bahisle açılan davada Esas Mahkemesi olarak yargılama yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 8.3.2007 tarih ve 49-13 sayı ile her bir sanığın 5237 s. TCK’ya nazaran lehe hükümler içer-

Haksız tahrikten bahsedebilmek için önce tahrik nedeni oluşturan bir **haksız fiilin** bulunması gerekir^{878,879}. Fiilin haksız olması yeterlidir⁸⁸⁰; fakat, suç teşkil etmesi gerekmez.

Tahrikin nedenini oluşturan fiil, icraî bir davranış olabileceği gibi, ihmalî bir davranış şeklinde de gerçekleşebilir⁸⁸¹.

Bu haksız fiil, failde hiddet (öfke, gazap) veya “*şiddetli elem*” meydana getirir⁸⁸². Hiddet, öfke ve gazap kelimeleri ile eş anlamlıdır⁸⁸³. Kanun, haksız

mesi itibarıyla 765 s. TCK'nın 266. maddesinin üçüncü fıkrası, 251. ve 59. maddeleri ve 647 s. Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. maddesi hükümleri uyarınca “2688 YTL” adlı para cezasıyla cezalandırılmalarına, “*ancak görevde hakaret fiillerinin karşılıklı olması ve her bir sanığın keyfî davranışlarıyla yekdiğerinin eylemine sebebiyet vermesi nedeniyle aynı Yasa'nın 272. maddesi uyarınca cezalarının ayrı ayrı kaldırılmasına*” hükmetmiştir.

⁸⁷⁸ «... G, reşit ve mümeyyiz bir kimse olup hayat tarzını dilediği gibi çizebilecek bir yaşta ise de; köklü geleneklerin hüküm sürdüğü çevrede en yakınlarını dahi üzecek birtakım olaylara ve kavgalara neden olacak şekilde, resmen evli, çoluk çocuk sahibi biriyle gayriresmî ilişki içine girmesi, yapılan uyarıları nazara almaması ve ... bu nedenle çıkan kavgada sanığın eşi ve yakınlarıyla karşılıklı kavga yapmaları ve sanığın eşinin bu kavgada dövülmesini sanık lehine tahrik olarak kabul etmek ve değerlendirmek gerekir.»: CGK., 28.4.1986, 91/255 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh.704).

765 s. «Türk Ceza Kanununun 51. maddesinin uygulanabilmesi için tahrikin *haksız* olması gerekir. Haksızlık keyfiyeti, kanunların tespit ettiği şartlar dışına çıkılması halinde sözkonusudur. Maktul tarafından sanığın kızkardeşinin ırzına geçilmesi suçu yasal takibe uğramış, bunun sonucu olarak kendisi tutuklanmıştır. O halde, ırza geçme fiili için kanunun öngördüğü tedbir alınmış, gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Kanunların (suç olarak tarif ettikleri) fiiller (dolayısıyla öngördüğü) cezaları kâfi görmemek halinin kanunla bağdaştırılması imkânsızdır. Aksi davranış, kanunun öngördüğü cezayı yeterli bulmayarak kişisel duygu, düşünce ve takdirle davranma sonucunu doğurur ki; bu hal bir taraftan kişileri haklarını kendiliklerinden almalarına yol açar, diğer taraftan anarşik bir ortam yaratır.»: CGK., 16.4.1979, 1-93/71 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh.722/723).

⁸⁷⁹ “Salt **borcu ödeyememenin** haksız tahrik oluşturan bir fiil olarak kabulü mümkün değildir. Borcuna karşılık senet veren, borcu inkar etmeyen, ekonomik sıkıntıları nedeniyle ödeyemediğini ancak ödemek istediğini söyleyen (borçlunun alacaklıya) yönelik tahrik oluşturabilecek başkaca bir davranışının bulunmadığı (durumlarda) haksız tahrik hükümlerinin uygulanma şartlarının gerçekleşmemiş” olduğunu kabul etmek gerekir.” CGK, **19.1.2016** tarihli ve E. 2015/14-203, K. 2016/2.

⁸⁸⁰ «4.12.1985 günü sabahleyin askerî servis aracına geç gelen sanığa, araçta bulunan M.nin “*niye geç kaldın, çocuğunun bezlerini mi değiştiriyordun*” diyerek takıldığı; bu söz üzerine sanığın M.ye “*şerefsiz herif, it oğlu it*” şeklinde karşılık verdiği; M.nin konuşmak üzere sanığın yanına gittiğinde, bu defa sanığın M.ye tokat attığı, böylece; sanığın mağdurun ağır ve haksız tahriki sonucu adiyen hakaret ve müessir fiil suçlarını işlediği» sonucuna varılmıştır: Askerî Yargıtay, 5. D., 8.7.1987, 448/435 (Ask. Yarg. KD 6[1990], sh. 111).

⁸⁸¹ «Şikayetçi, ineğini bağlamamış, gerekli önlemleri almamış, henüz altı yaşında bulunan kızının nezaretine bıraktığı inek, sanığın mısır tarlasına girerek zarar vermiştir. Gerekli özen gösterilmemiş ve önlem alınmamıştır. Sanık; şikayetçinin ihmalî sonucu ineğin tarlaya zarar vermesinin doğurduğu öfke altında yüklenen suçu işlemiştir. Bu nedenle sanık hakkında TCK'nın 51/1. maddesinin uygulanması yerindedir.»: CGK., 24.12.1990, 8-340/357 (YKD, Nisan 1991, sh. 608 vd.).

fiil neticesinde kişide hiddet veya “şiddetli elem”in meydana gelebilmesini öngörmüştür⁸⁸⁴. Ancak, hiddet kavramının yanı sıra kanun metninde ayrıca “şiddetli elem” ifadesine yer verilmesine gerek olmadığı düşüncesindeyiz⁸⁸⁵.

Kişi, kendi haksız hareketiyle olaya sebebiyet vermişse; artık haksız tahrikin varlığından bahsedilemez^{886,887}.

Suç bu gazap ve hiddetin etkisiyle işlenmiş olmalıdır. Buna göre, işlenen haksız fiille daha sonra işlenen suç arasında mutlaka bir illiyet ilişkisinin mevcut olması gerekir. Haksız fiilin meydana getirdiği gazap ile işlenen suç arasında bir zaman fasılasının geçmiş olması haksız tahrikin varlığına engel değildir⁸⁸⁸. Ancak, bu durumda suçun daha önce işlenmiş olan haksız fiilin meydana getirdiği gazabın etkisiyle işlenmiş olduğunun tespit edilmesi gerekir⁸⁸⁹.

⁸⁸² «... (H)aksız tahrik; failin, haksız bir fiilin meydana getirdiği gazap veya şiddetli bir elemnin etkisi altında bir suç işlemesidir. Haksız fiillerin neler olduğu kanunda belirtilmediği gibi, gazap ve elem gibi iki sebepten husule gelen bu mazeretin kabulü ve bunun sanık üzerindeki etkisi ve kronometre veya benzeri bir ölçü aleti ile ölçülemez. Tahrik hususunda hükme medar olacak kıstaslar ... mazeret sebebinin hukuki ve ahlakî mahiyetinde aranmalıdır.

Kanunda tahrikin, hafif ve ağır olmak üzere, iki şeklinden söz edilmiş; fakat birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak kesin bir kıstas veya tahdit konulmamıştır. “Ağır ve şiddetli” olursa denilmekle yetinilmiştir. O halde, tahrikin derecesinin takdiri hakime ait bulunmaktadır. ... (E)ğer haksız fiil, niteliği ve işleniş biçimi itibarıyla önemli boyutlara ulaşmışsa; tahrik ağırdır. Aksi halde, yani bu boyutlara ulaşmayan tahrikin hafif kabul edilmesi zorunludur. Gerçekten, meşru müdafaa niteliğinde olmayan ağır müessir fiillerde kabul edilecek bir tahrik derecesi bulunmayacaktır.»: CGK., 19.2.1979, 521/77 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 708).

⁸⁸³ '89 Öntasarısı, m. 32 gerekçesi, sh. 220; '97 Öntasarısı, m. 32 gerekçesi, sh. 174.

⁸⁸⁴ «Tahrikin varlığı ve derecesi, failin durumuna ve mahallî şartlara göre değerlendirilmeli; olayın işleniş şekli, niteliği, özellikleri, tahrik eden ile failin hal ve davranışları, aralarındaki ilişki, zaman ve yer şartları nazara alınmalıdır.

Ceza Kanunu, *öfke ve üzüntüyü* aynı nitelikte kabul etmiştir. *Üzüntü halinde derhal bir reaksiyonda bulunmasa dahi; bu psikolojik durumun devam ettiği süre içinde suçun işlenmesi halinde tahrik sözkonusudur.*»: CGK., 1.2.1993, 1-361/20 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh.715).

⁸⁸⁵ Nitekim TCK Hükümet Tasarısı, m. 31 gerekçesi; '89 Öntasarısı, m. 32 gerekçesi; '97 Öntasarısı, m. 32 gerekçesi.

⁸⁸⁶ «Maktûlün sanığa mukabeleten sövmesi, sanık lehine 51. maddenin uygulanmasına neden olmaz.»: CGK., 30.4.1984, 1-72/160 (Önder II, sh. 379). «Olayın çıkmasına kendi sebebiyet vermiş veya ilk tecavüz kendisinden gelmiş olan şahıs, TCK'nın 51. maddesindeki hükümden yararlanamaz.»: CGK., 3.5.1982, 1-64/176 (Önder II, sh. 379).

⁸⁸⁷ “... gerek fail gerekse maktûlün **karşılıklı haksız davranışlarda bulunması** halinde, tahrik uygulamasında kural olarak, haksız bir eylem ile maktûl tahrik eden fail, karşılaştığı tepkiden dolayı tahrik altında kaldığını ileri süremez. Ancak maruz kaldığı tepki, kendi gerçekleştirdiği eylemle karşılaştırıldığında aşırı bir hal almışsa, başka bir deyişle tepkide açık bir oransızlık varsa, bu tepkinin artık başlı başına haksız bir nitelik alması nedeniyle fail bakımından haksız tahrik oluşturduğu kabul edilmelidir.”: CGK, **18.12.2012**, E. 2012/1-1288, K. 2012/1856. Ayrıca bkz. CGK, **22.3.2016**, E. 2014/1-265, K. 2016/137.

⁸⁸⁸ DÖNMEZER/ERMAN II no. 1099; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 381/382.

⁸⁸⁹ «Haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için kanunda bir zaman sınırlaması mevcut değildir. Tahriki teşkil eden fiilin faili bu suç nedeniyle mahkûm edilmiş ve cezası infaz edil-

Suçun, tahrik nedenini oluşturan haksız fiili işleyen kimseye karşı işlenmesi gerekir. Bu itibarla, tahrik nedenini oluşturan haksız fiili işleyen kimseden başka birisine karşı suçun işlenmiş olması halinde haksız tahrik hükümleri uygulanmayacaktır.⁸⁹⁰

Buna karşılık, haksız fiile maruz kalan kişiyle suç işleyenin aynı şahıs olması şart değildir.⁸⁹¹

Haksız tahrik açısından önem arzeden hususlardan birisi, haksız tahriki oluşturan fiil ile bunun etkisiyle yani gazap ile işlenen suç arasında bir oranın olması gerekip gerekmediğidir. Bir görüşe göre, burada bir oranın bulunması gerekir.⁸⁹²

miş olsa bile; bu haksız fiilin *öfke ve şiddetli elem etkisi* altında bulunan ve bu ruhî durumun tepkisi ile suç işleyen kimse hakkında da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Aradan uzunca bir zaman geçse bile, önceki olay, sanığı bu suçu işlemeye itmiş ise tahrik hükümleri uygulanmalıdır.

Maddi olayda; sanık, dört yıl önce kardeşini öldüren ve şartlı tahliye edilerek köye dönen mağduru bu olayın etkisi ve olay öncesi söylediği sözlerin oluşturduğu *gazap ve şiddetli elem tesiriyle* öldürmeye teşebbüs ettiğinden hakkında ağır tahrik hükümleri uygulanmalıdır.»: CGK., 1.11.1993, 1-261/286 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 698).

⁸⁹⁰ CGK., 04.03.2008, 2008/1-2, 2008/42.

«Suçun haksız tahrikin etkisi altında işlenmiş sayılabilmesi için fail tarafından yapılan hareketin, haksız tahriki oluşturan failin sebebiyet verdiği gazap ve elemnin bir tepkisi olması gerekmektedir; *sanığın fiilinin de haksız tahrik teşkil eden fiili işleyen kimseye yönelmiş olması gerekmektedir*.

Kanun, birisine kızıp da hincını başka bir kimseden alanları korumayacağı için; haksız tahrikin bulunması, tepkinin tahrik teşkil eden fiili yapan kimseye yönelmiş olmasına bağlıdır.»: CGK., 28.3.1983, 1/492-142 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 707).

«Tahrikin bir *mazeret sebebi* olarak kabulüne saik olan düşünce, haksız hareketin fail üzerinden husule getirdiği teessürdür. Tahrik edici hareketin suçluya karşı yöneltilmiş olması zarurî olmadığı gibi; tahrik edilen kimsenin fiili hemen tahrik akabinde işlemiş olması da şart değildir.»: CGK., 3.12.1973, 2-199/780 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh.711).

⁸⁹¹ «Mağdur haksızdır. Haksız tahrikin faile karşı işlenmiş olması şart değildir. Haksız fiilin failin yakını bir kimseye veya failce sayılan bir kişiye veya faile tamamıyla yabancı bir şahsa karşı işlemiş olabilir. ... Failde, hiddet veya şiddetli elem yaratan tahrik fiilinin hedefi çok geniş bir mana taşımaktadır. Tahrik fiili, niteliği itibarıyla sürekli hiddet veya eleme neden olabilir. Suçun tahrikten hemen sonra işlenmesi zorunlu(lu)ğu yoktur. Zira, failde haksız tahrikin yarattığı hiddetin veya şiddetli elemnin etkisi sürebilir.»: CGK., 6.6.1983, 1-43/275 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh.719/720).

«Öldürülen H.nın semt sinemasında film seyrederken sanığın önde oturan bayanın sandalyesine değmesi üzerine kimlikleri tespit edilemeyen bayan ve kocası ile öldürülen arasında çıkan tartışmaya M müdahale edip kendilerini yatıştırdığı; bir süre sonra sinemadan çıkan ölen H.ya, aynı sinemada bulunan sanığın, “yaşlı bir adamın; sarkıntılık etmeye utanmıyor musun?” diyerek bir tokat attığı, üzerine gelen öleni yaraladığı, hastaneye götürülürken yaralının dış kanama sonucu öldüğü anlaşılmıştır.

Kimlikleri tespit edilemeyen şahıslarla öldürdüğü şahıs arasında cereyan eden ve kendisini hiçbir surette ilgilendirmeyen olay (üzerine) öldürülene yaklaşip “kadına sarkıntılıkta bulunmaya utanmıyor musun?” diye tokatlaması ve akabinde de bıçakla yaralamış bulunması gözönünde tutularak olayda sanık lehine tahrik sebebi bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.». CGK., 13.11.1989, 1-286/342. (YKD, Ekim 1990, sh. 1536 vd.).

⁸⁹² DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1104.

Buna karşılık, diğer bir görüş, suçun haksız fiilin oluşturduğu gazabın etkisinde işlenmiş olmasını yeterli görür. Buna göre, işlenen suçun ağırlığı ne olursa olsun, haksız tahrike ilişkin hükümlerin uygulanması gerekir⁸⁹³. Yargıtay, bu ikinci görüşe taraftar olmuştur⁸⁹⁴. Haksız tahrik açısından önemli olan, kişinin maruz kaldığı haksız fiilin kendisinde bir gazap ve hiddet oluşturup oluşturmadığıdır. Eğer somut olayda *gerçekten* gazap ve hiddetin olduğu sonucuna ulaşılmış ise, artık söz konusu oranın varlığını araştırmaya gerek olmayacaktır⁸⁹⁵.

⁸⁹³ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 383.

⁸⁹⁴ «Çocuk çocuğunun nafakasını çobanlıkla temin eden A, H'nın çobanıdır. Otlattığı sürü kendisinin değildir. Olaydan üç gün önce sanık geceleyin dağda sürüsünün başında uyurken, otlattığı sürü dağılmış, uyanıp bu durumu görünce sürüyü toplamış sayım sonunda sürüden iki koyun ile onbir çanın eksik olduğunu görmüştür. Yaptığı soruşturmada, kaybolan koyunlarının ve çanların Y tarafından çalındığına kanaat getirerek, o gece yine sürünün dağılmasını ya da koyun çalınmasını önlemek için sürüsünü yolun kenarına yatırmış kendisi de başına yatmıştır. *Gece yarısı mağdurun gelerek sürüden 8-10 koyunu ayırıp götüreceği sırada uyanmış, bu durumu görünce sopasıyla mağdurun kafasına birkaç kez vurarak öldürücü nitelikte yaralar husule getirmiştir.*

Kuşkusuz bu olaydan birkaç gün önce sanığın gütmekte olduğu sürüden iki koyun ile çanların çalınması ve bu hırsızlığın mağdur tarafından yapıldığının sanık tarafından saptanması ve olay gecesi saat 24.00 sıralarında da mağdurun yine sanığın beklemekte olduğu sürüden ... koyun çalmaya teşebbüs etmesi, sanık üzerinde büyük bir tepki ve gazap husule getirmiştir.

Çocuk çocuğunun nafakasını çobanlıkla temin eden sanık, sürüsünü korumakla yükümlü olduğu gibi, kaybettiği ya da çaldığı koyunlar bakımından da işverene karşı sorumlu bulunmakta ve geleceği işverenin “işine son verdim” şeklindeki takdirine bağlı bulunmaktadır.

Bu itibarla; gerek yaptığı işin niteliği, gerek ekonomik güçsüzlüğü, daha doğrusu yoksulluğu, sanığın mağdurdan gelen haksız hareket karşısında daha ağır bir tahrike kapılmasına neden» olmuştur: CGK., 17.12.1984, 1678/441.

Kanun bir suçun işleniş sırasında veya hemen akabinde herhangi bir kişiye dahi suç failini yakalama yetkisi vermektedir (CMUK, mad. 127) (“Kanunun hükmünü icra (yerine getirme)” veya “görevin ifası” hukuka uygunluk sebebi). Bu yetki faili yakalamaktan, yani kaçmasını önlemekten ibarettir.

Bu yetkinin kullanımı sırasında suçu işleyen kişiye yakalamaya ve tutmaya matuf gücün dışında müessir fiilinde bulunulması (meselâ dövülmesi), suç olma vasfını taşıyacaktır. Bu hususa kararda işaret edilmemesi bir eksiklik olarak telâkki edilmekle birlikte; kanımızca Yargıtay aynı düşünceden hareket etmiştir.

Burada, sözkonusu olan hukuka uygunluk sebebinin sınırı, korku telaş ve panik dolayısıyla aşılmamıştır. Şayet yakalamaya ve tutmaya matuf fiil sırasında meydana gelen çekişmede suçlu kişiye yönelik gerekenden fazla kuvvet kullanılmış olsaydı; bunun, içinde bulunulan telaş halinden kaynaklandığını söyleyebilirdik. Ancak, olayda suçlu kişinin yakalanmasını temine, kaçmasının önlemeye matuf fiilden ziyade, hırsızlık teşebbüsünden duyulan öfke dolayısıyla fiile karşı ika edilmiş müessir fiil sözkonusudur. Bu itibarla, karardaki haksız tahrike ilişkin değerlendirmelere aynen iştirak ediyoruz.

⁸⁹⁵ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**’nun 12.4.2011 tarihli ve E. 2011/1-51, K. 2011/42 sayılı Kararında yer verilen **karşılıklı tahrikle** ilgili şu açıklamalar önem arz etmektedir:

“... (G)erek fail gerekse, maktûlün **karşılıklı haksız davranışlarda** bulunması halinde, tahrik uygulamasında kural olarak, haksız bir eylem ile maktûl tahrik eden fail, karşılaştığı tepkiden dolayı tahrik altında kaldığını ileri süremez. Ancak maruz kaldığı tepki, kendi gerçekleştirdiği eylemle karşılaştırıldığında aşırı bir hal almışsa, başka bir deyişle tepkide açık bir oran-

Haksız tahrik hükümleri açısından, maruz kalınan haksız bir fiilin oluşturduğu gazap ve hiddetin etkisinde işlenen suçun münhasıran kasten işlenen suç olup olmayacağı tartışılmıştır. Bir görüşe göre, haksız tahrik ancak kasten işlenen suçlarda gerçekleşebilir. Bu itibarla, yolcuya kızıp da bir üçüncü şahsa çarpan şoförün haksız tahrik halinde olduğu söylenemez⁸⁹⁶. Bizim de iştirak ettiğimiz diğer bir görüşe göre ise; maruz kalınan haksız bir fiilin oluşturduğu gazap ve hiddetin etkisinde işlenen suç ister kasten ister taksirle işlenen bir suç olsun, genel haksız tahrik hükmüne (m. 29) istinaden failin cezasında indirim yapılabilmelidir^{897, 898}. Çünkü haksız tahrik hali açısından önemli olan, maruz kaldığı haksız bir fiilin kişide gazap ve hiddet oluşturup oluşturmadığı ve suçun bunun etkisinde işlenip işlenmediğidir. Eğer suç bu haksız fiilin oluşturduğu gazap halinin etkisinde işlenmiş ise; bu, işlenen suç açısından failin irade kabiliyetinin zayıflamış olduğu anlamına gelecektir. Dolayısıyla, bu husus, işlediği suçla ilişkin olarak failin kusurunun tayininde dikkate alınacaktır.

Mülga 765 s. TCK'nın 51. maddesinin ikinci fıkrasına göre, tahrikin “ağır ve şiddetli” olması halinde, failin cezasında maddenin birinci fıkrasına nazaran daha fazla indirim yapılmaktaydı⁸⁹⁹. Buna karşılık, yeni TCK'nın sisteminde ise, tahrikle ilgili olarak adi ve ağır tahrik olarak bir ayırım öngörülmemiştir. Tahrik ol-

sızlık varsa, bu tepkinin artık başlı başına haksız bir nitelik alması nedeniyle fail bakımından haksız tahrik oluşturduğu kabul edilmelidir.

Karşılıklı tahrik oluşturan eylemlerin varlığı halinde, fail ve maktûlün tahrik oluşturan haksız davranışları birbirlerine oranla değerlendirilmeli, öncelik-sonralık durumları ile birbirlerine etki-tepki biçiminde gelişip gelişmedikleri göz önünde tutulmalı, ulaştıkları boyutlar, vahamet düzeyleri, etkileri ve dereceleri gibi hususlar dikkate alınmalı, buna göre; etki-tepki arasında denge bulunup bulunmadığı gözetilerek, failin başlangıçtaki haksız davranışına gösterilen tepkide aşırılık ve açık bir oransızlık saptanması halinde, failin haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılması yoluna gidilmelidir.” Aynı yönde başka bir karar için ayrıca bkz. CGK, **19.4.2011**, E. 2011/1-47, K. 2011/56; CGK, **28.6.2011**, E. 2011/1-99, K. 2011/145; CGK, **18.12.2012**, E. 2012/1-1288, K. 2012/1856; CGK, **5.2.2013**, E. 2012/1-1416, K. 2013/41.

⁸⁹⁶ GÜRELLİ, İBD1951, sh. 339.

⁸⁹⁷ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1091; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 380.

⁸⁹⁸ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun **5.10.2010** tarihli ve E. 2010/1-132, K. 2010/183 sayılı kararında ifade edildiği gibi, “sanık ve yanındaki kız arkadaşı tarafından ‘küfür’ olarak algılanan hareketin sanık yönünden ‘haksız tahriki’ oluşturacağı ve **olası kastla işlenen suçlarda da “haksız tahrik” hükümlerinin uygulanmasına bir engel bulunmadığı** kabul edilmelidir.”

⁸⁹⁹ Maddi bir sorun olması itibarıyla, somut olaydaki tahrikin “ağır ve şiddetli” olup olmadığının takdirinin esas mahkemesine ait olduğu kabul edilmektedir:

765 s. «TCK'nın 51. maddesinde yer alan *tahrikin* uygulanmasının *şartları*; mağdurun haksız hareketi, bu hareketin sanıkta uyandırdığı öfke ve bu öfkenin etkisiyle, nedensellik zinciri içinde, failin suç işlemesidir. İlk mahkemeler bu koşulların varlığını fiilen saptamak ve bunları, gerekçe gösterme zorunluluğunun sonucu olarak, kararlarında yansıtmak zorundadırlar. Öte yandan ilk mahkeme yargıçları, olayın akışına, sanığın hoşgörü ve katlanma gücüne göre, haksız eylemin, onda uyandırdığı tepkinin ve dolayısıyla tahrikin derecesini bu fiili saptamalar doğrultusunda takdir edeceklerdir. Bir başka deyişle, sorun fiilidir, hukuki değildir.» Üye S. Selçuk'un CGK'nın 18.12.1984 tarih ve 1-420/439 sayılı kararına muhalefet şerhi (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh.732/733).

gusu kişinin iradesini etkileyen bir neden oluşturduğuna göre, somut olayın şartları göz önünde bulundurularak, maddede belirlenen alt ve üst sınırlar arasında tayin edilecek bir oranda failin cezasında indirim yapılacaktır⁹⁰⁰. Mahkeme, bu indrimi Kanunun 61. maddesinin beşinci fıkrasına öngelen fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden ve bu beşinci fıkradaki sırayı gözeterek yapacaktır.

Somut olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir haksız fiilin varlığı halinde; bu nedenle ayrıca cezada artırma yapılamaz. Nitekim, Kanunun 82. maddesine göre, kasten öldürme suçunun “*kan gütme saikiyle*” (bent j) veya “*töre saikiyle*” (bent k) işlenmesi halinde, faile suçun temel şekline göre daha ağır ceza verilecektir. Ancak, madde gerekçesinde açıkça vurgulandığı üzere, “*kan gütme saikiyle öldürme hâlinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmesi, fiilin sadece kan gütme saikine bağlı olarak işlenmiş olması hâlinde söz konusu olabilecektir.*” Buna karşılık, **haksız tahrikin koşullarının bulunduğu hâllerde, suçun kan gütme saikiyle işlendiğinden bahisle daha ağır cezaya hükmolunamaz**⁹⁰¹. Kasten öldürme suçunun “*töre saikiyle*” işlenmesi halinde de “*ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilecektir. Ancak, bu* (nedenle fail hakkında daha ağır cezaya hükmedilebilmesi) *için, somut olayda haksız tahrikin koşullarının bulunmaması gerekir.*”⁹⁰².

⁹⁰⁰ Toroslu, yeni TCK’nın bu düzenlemesini olumlu değerlendirmektedir (TOROSLU, Genel Kısım, 8. bası, sh.243).

⁹⁰¹ CGK, 30.3.2010, E. 2009/1-228, K. 2010/69.

⁹⁰² Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 14.6.2011 tarihli ve E. 2011/1-138, K. 2011/130 sayılı Kararında yer verilen, “*töre saiki*” kavramı ve **haksız tahrik hükümlerinin uygulanabileceği hallerde kasten öldürme suçunun töre saikiyle işlendiğinin kabul edilemeyeceğine** dair açıklamalar, önem arz etmektedir:

“Töre belli koşullarda namusu da içine alan bir üst kavram ise de, öncelikle töre ve namus cinayetlerinin aynı kapsamda olmadığı belirtilmelidir. Ait olunan toplulukta geçerli ve herkes tarafından kabul edilen töre gereğince namus cinayeti işlenmesi olanaklı olup bu durumda kasten öldürme fiilinin töre saikiyle işlendiği kabul edilebilir. Ancak bununla birlikte toplumda “namus cinayeti” olarak adlandırılan her kasten öldürme eyleminin töre saikiyle işlenmediği ve bu tür eylemlerin kişilerin kendi namus anlayışının bir sonucu olarak ve töre ile yakından uzaktan ilgisi olmayacak şekilde gerçekleştirildiği de gözden uzak tutulmalıdır.

Töre saikiyle hareket ederek kasten öldürme suçunu işleyen **fail**, görev bilinciyle hareket etmekte ve hukuk düzenince uygun görülerek cezalandırılan bu davranışı nedeniyle **ait olduğu toplulukta saygınlık ve itibar kazanmakta, hoş görülmekte ve korunmaktadır**. Oysa töre saikinden bağımsız olarak kendi namus anlayışının bir sonucu olarak kasten öldürme fiilini gerçekleştiren fail açısından aynı durum söz konusu olmamaktadır.

...

Diğer taraftan 5237 sayılı TCY’nın “*Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi*” başlıklı 2. maddesinin üçüncü fıkrasında; “*Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılmaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz*” hükmü getirilmiştir. Maddenin gerekçesinde; “*Böylece ceza kanunlarının bireye güvence sağlama işlevinin bir gereği daha yerine getirilmiş olmaktadır. Yeni tarihli ceza kanunlarında da kıyas yasağına ilişkin olarak açık hükümlere yer verilmektedir. Örneğin yeni Fransız Ceza Kanununda bu husus ‘ceza kanunları dar yorumlanır’ biçiminde ifade edilmiştir. Kıyas yasağıyla getirilen güvencenin*

Tasarlamanın (taammüdün) hukuki esasını açıklayan soğukkanlılık ve plan kurma teorileri kapsamında, tasarlama ile haksız tahrik halinin bir arada bulunup bulunamayacağı hususu da tartışılmıştır. Tasarlamayı soğukkanlılıkla açıklayan görüş, öfke ve gazap halini ifade eden haksız tahrikle taammüdün bir arada olamayacağını savunmuştur⁹⁰³. Buna karşılık Türk doktrininde, tasarlama

tam anlamıyla uygulanabilmesini mümkün kılmak amacıyla, kıyasa yol açacak şekilde yapılacak geniş yoruma da başvurulmayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak bu hükümle ceza hukukunda genişletici yorum tümüyle yasaklanmamakta, sadece bu yorum biçiminin kıyasa yol açacak şekilde uygulanmasının önüne geçilmek istenmektedir” denilmiştir.

Gerek 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının hazırlık çalışmaları, gerekse öğretideki görüşler yasal düzenlemeler ile birlikte değerlendirildiğinde, **yasa koyucunun bilinçli bir tercih olarak “töre saiki” kavramına yer verdiği ve “namus saiki” kavramını kullanmadığı**, töre saiki ile işlenen namus cinayetlerinin bu kapsamda mütalaa edilmesini arzu ettiği, buna karşın **toplumda “namus cinayeti” olarak adlandırılan her kasten öldürme fiilini töre saikiyle kasten öldürme içinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir iradesinin bulunmadığı** sonucuna ulaşılmaktadır. Yasa koyucunun öngörmediği bir şekilde namus saiki ile töre saiki kavramlarının özdeşleştirilmesi, yasa maddesinin kıyasa yol açacak şekilde geniş yorumlanmasıdır ki buna 5237 sayılı TCY’nın 2/3. maddesi uyarınca yasal olanak bulunmamaktadır.

...

Töre saikiyle işlenen suçlarda haksız tahrik özel bir öneme sahip olup madde ile ilgili yasama çalışmalarında; *“Maddedeki düzenleme nedeniyle bir suçun mağduruna yönelik olarak gerçekleştirilen fiiller dolayısıyla fail haksız tahrik indiriminden yararlanamayacaktır. Örneğin cinsel saldırıya maruz kalmış kadına karşı babanın veya erkek kardeşin işlediği öldürme fiilinde, haksız tahrike dayalı olarak ceza indirimi yapılamayacaktır. Maddedeki haksız fiil terimi, bir davranışın hukuk düzenince tasvip edilmediği anlamına gelmektedir. Ancak böyle bir haksız fiili yapan kişiye karşı yönelik fiilin varlığı durumunda maddenin uygulanması söz konusu olabilecektir”* şeklinde açıklanmış, maddenin gerekçesinde de; *“töre saikiyle öldürme hâlinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilecektir. Ancak, bu hükmün uygulanabilmesi için, somut olayda haksız tahrikin koşullarının bulunmaması gerekir”* denilmiştir.

5237 sayılı TCY’nın 29. maddesinde ise; *“Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemi etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirilir”* şeklinde kusurluluğu azaltan bir neden olarak düzenlenen haksız tahrik, failin haksız bir tahrikin yarattığı hiddet veya şiddetli elemi etkisi altında hareket ederek bir suç işlemesini ifade eder. Bu halde fail, haksız bir tahrikin doğurduğu öfke veya elemi tesiri altında, suç işleme yönünde önceden bir karar vermeksizin, dışardan gelen etkinin ruhsal yapısında yarattığı karışıklığın sonucu olarak suç işlemeye yönelmektedir.

Görüldüğü gibi **kasten öldürme suçunun töre saikiyle işlenmesi halinde, haksız tahrik hükümleri uygulanmayacak**, tahrikin varlığı halinde ise suç niteliği değişecektir.”

Ayrıca bkz. CGK, 3.7.2012, E. 2012/1-76, K. 2012/258; CGK, 20.9.2011, E. 2011/1-52, K. 2011/180; CGK, 11.5.2010, E. 2010/1-56, K. 2010/111.

⁹⁰³ CGK., 29.11.1983, 1-244/383 (İKİD, Mart 1984, sh. 2437).

«Maktülle kardeşi olay günü saat 11 sıralarında sanıkla kahvede kavga ettikleri, maktülün kardeşi sanığı dövdüğü gibi maktülün de sanığa söverek onu kahveden dışarı attığı; aynı gün saat 19 sıralarında sanığın kahvede gördüğü maktülü öğleyin yediği dayak ve uğradığı hakaretin tesiri altında vurup öldürdüğü, nitekim bu nedenle de sanık hakkında tahrik hükmünün de uygulandığı ... anlaşıldığına göre; olayın, olay günü sanığın uğradığı haksız tecavüzün devam

halinde işlenen bir suçun failinin de haksız tahrik hükümlerinden yararlanabileceğine dair görüş hakim bulunmaktadır⁹⁰⁴.

Haksız tahrik nedeniyle cezada indirim yapılabilmesi için, somut olayda haksız tahrike ilişkin koşulların gerçekleşmesi gerekir. Haksız tahrike ilişkin koşullar somut olayda gerçekleşmediği halde kişi bu şartların gerçekleştiği zannıyla hareket etmiş olabilir. Örneğin bir başkası ile gayrimeşru ilişkide bulunduğunu zannettiği eşine karşı kasten öldürme suçunu işleyen kişi **haksız tahrikin maddi şartlarında yanlış**ya düşmüştür. Eşi gerçekte bir başkasıyla gayrimeşru ilişkide bulunmamaktadır. Fakat fail, bu gayrimeşru ilişkinin varlığını zannetmektedir. Bu hatasının, içinde bulunduğu koşullar bakımından **kaçınılmaz** olması halinde; fail hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekir (m. 30, f. 3). Ancak, bu hatasının **kaçınılabılır** olması halinde; fail bu hatasından yararlanamaz. Bu durum ancak, 61. maddenin birinci fıkrası hükmüne göre temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilir⁹⁰⁵.

eden etkisi altında işlendiğinin kabulü gerekirken; ... fiilin taammüden işlendiğinin kabulü» doğru değildir: 1. CD., 5.5.1976, 1271/1651 (YKD. Ekim 1976, sh. 1497).

⁹⁰⁴ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 949; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh.322; ÖZTÜRK, Ceza Hukuku(3), sh. 209, 233 vd. Yargıtay'ın yeni tarihli kararlarında haksız tahrikle taammüdün bir arada olabileceği fikri kabul edilmektedir: 1. CD., 19.4.1988, 1779/1697 (YKD, Eylül 1988, sh. 1285).

⁹⁰⁵ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 15.3.2016 tarihli ve E. 2014/3-436, K. 2016/134 sayılı kararına konu teşkil eden olayda, F, baldızının oğlu olan ve kendisinden 34 yaş küçük M ile birlikte denizde yüzerler. Bu sırada M, F'ye, "köpek stili yüzüyorsun, köpek yüzüşü yapıyorsun" der. F, bu ifadeyi kendisine hakaret olarak değerlendirebilir. Aile bireylerinin, bu sözü yanlış anladığını, M'nin hakaret kastının olmadığını F'ye söylemesine rağmen, F, bu sözün etkisiyle M'yi bıçakla yaralar.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıdaki gerekçelerle F hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması yönünde içtihatla bulunmuştur:

"bu sözleri yanlış anlayan ve kendisine köpek denildiğini düşünen sanığın, katılanın ailesinin araya girerek kendisine hakaret edilmediğine ilişkin açıklamalarına rağmen, ... yanına aldığı ekmek bıçağı ile ... katılanı ... bıçakla ... yaraladığı ... olayda, katılanın herhangi bir suç işleme kastı taşımadan söylediği beğeni ifade eden, literatürde "köpekleme yüzme stili" olarak da bilinen, başın dışarıda tutulup, su içerisinde koşmaya benzeyen ve zor öğrenilen bir yüzme şekli olan "köpek stili yüzüyorsun" biçimindeki sözlerin hakaret vasfı içermediği gibi, kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte de olmadığı, bu durum karşısında sanığın, eşinin yeğeni olan, aralarında önceye dayalı başkaca bir sorun ya da husumet bulunmayan, ... olay tarihi itibarıyla onsekiz yaşında bulunan katılanı bıçakla ... kasten yaralama eylemini, katılanın söylediği sözlerin, dolayısıyla katılandan kaynaklanan haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ya da şiddetli elemin etkisi altında kalarak gerçekleştirdiğini kabule imkân bulunmamaktadır."

Karara konu teşkil eden olayda M'nin sarf ettiği sözlerin hakaret mahiyeti taşımadığı kuşkusuzdur. Ancak F, bu sözle kendisine hakaret edildiğini düşünmüştür. Bu nedenle F, haksız tahrikin maddi şartlarından biri olan haksız fiilin varlığı hususunda hataya düşmüştür. Şayet bu hatası kaçınılmaz ise; TCK, m. 30, f. 3 hükmü gereğince, F'nin bu hatasından yararlanması ve hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekir. Ancak, olayda F'ye aile bireyleri tarafından M'nin bu sözle kendisine hakaret etmediği, M'nin böyle bir kastının olmadığı müteaddit defa beyan edilmesine rağmen, F'nin bu değerlendirmesinde ısrar etmesi, bu hatasının kaçınılmaz olmadığını göstermektedir.

Sonuç itibarıyla doğru olsa bile, Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararında TCK, m. 30, f. 3 hükmünün göz ardı edilmesi, önemli bir bilgi eksikliğine işaret etmektedir.

765 sayılı TCK'ya ilişkin hukuk uygulamamızda bu durumda “*mefruz haksız tahrik*” halinden söz edilmekteydi⁹⁰⁶.

Ayrıca belirtilmelidir ki, “*haksız tahrik, haksız bir fiilden etkilenen failin ruhsal durumundan dolayı kusurunun azaldığı görüşüne dayanmakta olup, buna göre müşterek failler yahut fail ve şerikler arasında yalnızca şahsında bu koşullar gerçekleşen fail bakımından uygulanmalıdır.*”⁹⁰⁷.

J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri

Bu konunun izahı, genel olarak hata konusu açıklandıktan sonra daha iyi anlaşılacağı düşüncesiyle, hata bahsinde yapılacaktır.

V. Kabahat Dolayısıyla Kusurluluk

5326 s. Kabahatler Kanununun 12. maddesine göre;

“Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza Kanununun ... kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.”

Madde gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Madde metninde, Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenleriyle kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerine ilişkin hükümlerinin kabahatler açısından da uygulanabileceği kabul edilmiştir. Ancak, Tasarıda aksine hüküm bulunan haller saklı tutulmuştur.

Türk Ceza Kanununun ... kusurluluğu etkileyen nedenlere ilişkin hükümleri ise, kusurluluğu azaltan veya ortadan kaldıran nedenler olarak iki gruba ayrılabilir. Maddenin düzenlemesine göre, hukuka uygunluk nedenleri ile zorunluluk hali, cebir veya tehdit etkisinde olma, hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi gibi kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerin varlığı halinde, idari para cezasına karar verilemeyecektir. Ancak, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile ilgili olarak Tasarıda ayrı hükümlere yer verilmiş olması dolayısıyla, Türk Ceza Kanununun bu hallere özgü hükümleri kabahatler açısından uygulanamayacaktır. Keza, Türk Ceza Kanununun örneğin haksız tahrik gibi kusurluluğu azaltan nedenlere ilişkin hükümleri, kabahatler açısından uygulanamayacaktır.”

⁹⁰⁶ Mefruz haksız tahrik halinde, bir görüşe göre işlenen suç dolayısıyla failin cezasında indirim yapılmaz (GÜRELLİ, Nevzat: Ceza Hukukunda Mazeret Sebebi Olarak Haksız Tahrik, İBD, 1951, sh. 333; ÖNDER, Genel Hükümler II sh. 378).

Yargıtay da bu görüşü benimsemiştir: 1 CD., 5.12.1986 3854/4441 (YKD, Mart 1987, sh. 464).

Buna karşılık, diğer bir görüş ise, bu halde de failin cezasında haksız tahrik nedeniyle indirim yapılması gerektiği düşüncesindedir (DÖNMEZER/ERMAN II no. 1103). Kanaatimizce, bu ikinci görüş, tercih edilmesi gereken görüştür.

⁹⁰⁷ CGK, 19.01.2016 tarihli ve E. 2015/14-203, K. 2016/2.

§19. Hata

Suç teorisinde hata,

- 1) kastı kaldıran hata,
 - 2) kusurluluğu etkileyen hata,
- olarak, ikiye ayrılmaktadır.

Kastı kaldıran hata,

- 1) suçun maddi unsurlarında hata (m. 30, f. 1),
 - 2) suçun nitelikli unsurlarında hata (m. 30, f. 2),
 - 3) hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarında hata (m. 30, f. 3),
- olmak üzere, üçe ayrılmaktadır.

Kusurluluğu etkileyen hata,

- 1) kusurluluğu ortadan kaldıran veya azaltan bir nedenin maddi şartlarında hata (m. 30, f. 3),
 - 2) işlenen fiilin esasında bir haksızlık oluşturduğu hususunda hata (m. 30, f. 4),
- olmak üzere, ikiye ayrılır.

I. Kastı Kaldıran Hata Halleri

A. Suçun Maddi Unsurlarında Hata

Suçun maddi unsurlarında hata, yeni TCK'nın 30. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir:

“Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır.”

Madde **gerekçesinde** bu hükümle ilgili olarak şu açıklamalar yer almaktadır⁹⁰⁸:

“Birinci fıkrada suçun maddi unsurlarında hataya ilişkin hükme yer verilmiştir. Kast, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik veya yanlış bilgi sahibi olunması durumu ise, maddi unsurlarda hata olarak adlandırılır. Böyle bir hata kastın varlığına engel olur. Örneğin, kişi vestiyerden kendisinininki zannederek başkasının paltosunu alır. Keza, kişi gece karanlığında vahşi bir hayvan zannıyla hareketli bir cisme ateş eder. Ancak, gerçekte bu hareket eden cisim bir insandır ve dolayısıyla; bu insan ölür veya yaralanır. Örnek olarak verilen bu olaylarda failin bilgisi

⁹⁰⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 434 vd.

gerçeğe uysaydı; işlediği fiil haksızlık teşkil etmeyecekti. Bu nedenle hata hâlinde kasten işlenmiş bir suçtan söz etmek mümkün değildir.

Fıkra da ayrıca, maddi unsurlarda hata hâlinde, taksirle sorumluluğa ilişkin olarak hükme yer verilmiştir. Buna göre, meydana gelen neticeye ilişkin olarak gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olsaydı böyle bir netice ile karşılaşılmazdı şeklinde bir yargıya ulaşılabiliyorsa; taksirle işlenmiş bir suç söz konusu olur. Ancak bu durumda neticenin taksirle gerçekleştirilmesinin kanunda suç olarak tanımlanmış olması gerekir. Bu nedenle, kendisinin sanarak başkasının çantasını alan kişinin yanlışlığında taksirin varlığı kabul edilse bile; kanunda hırsızlık fiilinin ancak yararlanma kasdıyla işlenebileceği belirtildiği için; böyle bir olay dolayısıyla ceza sorumluluğu doğmayacaktır. Buna karşılık, av hayvanı zannederek gerçekte bir insana ateş edip onun ölümüne neden olan kişinin bu hatasında taksiri varsa, adam öldürme kanunda taksirle işlenen bir suç olarak da tanımlandığı için, böyle bir olayda fail, taksirle adam öldürme suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır.

Kastın varlığına engel olan hata, suçun sadece temel şekline ilişkin unsurlar hakkında değil, aynı zamanda failin daha ağır veya hafif ceza ile cezalandırılmasını gerektiren nitelikli unsurları bakımından da ortaya çıkabilir. İkinci fıkra ile kişinin, suçun nitelikli unsurlarına ilişkin hatasından yaralanması öngörülmüştür.

Hükûmet Tasarısının 23. maddesinin birinci fıkrasında 765 sayılı Türk Ceza kanunun 52. maddesinde düzenlemeye paralel olarak şahısta hata ve hedefte sapma hâli düzenlenmiştir.

“Şahısta hata” aslında bir ve ikinci fıkra hükümleri bağlamında düşünülmesi gereken bir durum olduğu için, bu hususa ilişkin ayrı bir hükme yer verilmesi gereksiz görülmüştür.

Keza, hedefte sapma hâli ile ilgili olarak bu madde kapsamında düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir. Çünkü hedefte sapma hâlinde bir hata söz konusu değildir. Bu durumda suçların içtimai hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gereken bir sorun söz konusudur. Nitekim, uygulamada da hedefte sapma, suçların içtimai ve özellikle fikrî içtima bağlamında ele alınmaktadır.”

Suçun maddi unsurlarında hata (unsur yanlışlığı)⁹⁰⁹, müşahhas bir olayda suçun maddi unsurlarına müteallik hususlardaki bilgisizliği, eksik veya yanlış bilgiyi ifade eder. Bir başka ifadeyle, faildeki müşahhas olaya ilişkin tasavvurun ger-

⁹⁰⁹ Suçun unsurlarında hata ile ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan nedenlerin maddi şartlarında hata hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “Kast-Taksir Kombinasyonları”, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Süleyman Arslan Armağanı, cilt 6, yıl 1998, sayı 1-2, sh. 159 vd.; ÖZGENÇ/ŞAHİN: *Uygulamalı Ceza Huku-ku*, 3. bası, Ankara 2001, sh. 193 vd., 213 vd..

çekle bağdaşmamasıdır. Meselâ, bir kimse vestiyerden kendisinininki zannederek başkasının paltosunu alır. Keza, bir kimse gece karanlığında vahşi bir hayvan zannıyla hareketli bir cisme ateş eder; ancak, gerçekte bu hareket eden cisim bir insandır ve dolayısıyla; bu insan ölür veya yaralanır.

Bu hata, suça ilişkin kastı ortadan kaldırır (m. 30, f. 1, birinci cümle). Bu hata halinde kasten işlenmiş bir haksızlıktan bahsetmek mümkün değildir⁹¹⁰. Failin bilgisi veya tasavvuru gerçeğe uysaydı; işlediği fiilin bir haksızlık teşkil etmeyeceği muhakkaktır.

Ancak, meydana gelen neticeye ilişkin olarak gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olsaydı böyle bir netice ile karşılaşılmazdı şeklinde bir yargıya ulaşılabiliyorsa; taksirle işlenmiş bir haksızlık söz konusu olur. Eğer söz konusu hukuki değer taksirle ihlâlî kanunda suç olarak tarif edilmişse; failin bu nedenle cezaî sorumluluğu cihe-tine gidilir (m. 30, f. 1, ikinci cümle). Bu itibarla, yukarıdaki “palto örneği”nde taksirin varlığı sonucuna ulaşılsa bile; Kanunda hırsızlık fiilinin ancak *yararlanma* *kastıyla* işlenebileceği belirtildiği için; fail cezaen sorumlu tutulmayacaktır⁹¹¹.

⁹¹⁰ Bkz. ERMAN, Ragıp Barış: Yanılmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi, sh. 24 vd.

⁹¹¹ “Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi olup, bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik ya da hatalı bilgi, maddi unsurlara ilişkin bir hatadır. Bu hatanın kastın varlığına engel olacak düzeyde bulunması halinde sanığa ceza verilmeyecektir. Suçun maddi unsurlarına ilişkin hata, eylemin suç teşkil etmesi için bulunması zorunlu hususlara ilişkin bir yanılmadır. Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, hata dolayısıyla taksirli sorumluluk halinin saklı olduğu belirtildiğinden, taksirle de işlenebilen bir suçun maddi unsurlarında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu hataya düşülmesi kusurluluğu ortadan kaldırmayacaktır. Örneğin, gerekli dikkat ve özeni göstermeden gece gördüğü karartıya av hayvanı olduğunu düşünerek ateş eden ve bir kişinin ölümüne neden olan fail, taksirle öldürmeden sorumlu olacaktır.

...

Fail, cinsel ilişkide bulunduğu mağdurenin 15 yaşını doldurmadığı halde, 15 yaşını doldurduğu düşüncesiyle mağdure ile rızasıyla cinsel ilişkide bulunur ve şikayetçi olmayan mağdurenin yaşı konusundaki hatası esaslı, diğer bir ifadeyle kabul edilebilir bir hata olursa, bu takdirde fail 5237 sayılı TCK'nın 30. maddesinin birinci fıkrası uyarınca suçun maddi unsurlarından olan **mağdurun yaşına ilişkin bu hatasından yaralanacak**tır.

Ancak, S ile M, aynı okulda öğrencidirler. Yaklaşık bir yıl süreyle arkadaşlık yaparlar. Lise üçüncü sınıf öğrencisi olan S, kendisi ile birlikte aynı okulda lise birinci sınıf öğrencisi olan M'nin 15 yaşından küçük olduğunu bilmektedir.

“Bu nedenle, onbeş yaşını tamamlamamış olan M ile zincirleme şekilde rızasıyla cinsel ilişkide bulunan ve M'yi alıkoyan S'nin **çocukların cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yok-sun kılma suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına** ilişkin yerel mahkeme kararı isabetlidir.” CGK, **5.11.2013**, E. 2013/14-573, K. 2013/432. Ayrıca bkz. CGK'nın **26.11.2013** tarihli ve K. 2013/514, 2013/515, 2013/516, 2013/517, 2013/518 sayılı; **12.11.2013** tarihli ve K. 2013/445 sayılı; **5.11.2013** tarihli ve K. 2013/440 sayılı; **3.12.2013** tarihli ve K. 581 sayılı; **24.12.2013** tarihli ve K. 2013/625, K. 2013/626 sayılı, **14.1.2014** tarihli ve K. 2014/8, 2014/9 sayılı; **21.1.2014** tarihli ve K. 2014/13, K. 2014/14, K. 2014/15 sayılı; **4.2.2014** tarihli ve K. 2014/33, K. 2014/34 sayılı; **11.2.2014** tarihli ve K. 2014/67, K. 2014/68 sayılı; **18.2.2014** tarihli ve K. 2014/76 sayılı; **25.2.2014** tarihli ve K. 2014/95 sayılı; **25.11.2014** tarihli ve E. 2013/14-790, K. 2014/518 sayılı, Kararları.

Bu yanlış aksî istikamette de olabilir. Meselâ kişi, müşterek ağıldan A'ya ait koyunu çalmak isterken, yanlışlıkla kendi koyununu alır. Kişi, hırsızlık suçunu işlemek kastıyla hareket eder. Ancak, hırsızlık suçunun çalınan şeyin başkasına ait olması gerektiği hususundaki unsuru müşahhas hadisede gerçekleşmez. Bu durumda *tersine unsur yanlışlığı* söz konusudur. Her ne kadar fail icra ettiği davranışla bir ahlâkî redaet içinde olduğunu izhar etmiş ise de; müşahhas hadisede bir başkasının hukukuna tecavüz edilmemiştir, bir haksızlık gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla, bu fiil nedeniyle kişinin cezaî sorumluluğu cihetine gidilmeyecektir: *elverişsiz teşebbüs, işlenemez suç*.

B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata

Suçun nitelikli unsurlarında hata da, bu unsura ilişkin kastı ortadan kaldırır ve kişinin sadece suçun temel şekline istinaden cezalandırılmasını gerektirir. Suçun nitelikli unsurlarında hata, yeni TCK'nın 30. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir:

“Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.”

Kişi, mağdurun kimliğinde yanlış olabilir. Meselâ kişi A'yı öldürmek isterken, yanlışlıkla B'yi öldürür. Mağdurun kimliğinde yanlış olmak, kanunî tarife uygun haksızlığın gerçekleşmesi bakımından, prensip olarak, bir önemi haiz değildir⁹¹². Çünkü, suçun kanunî tarifindeki unsurların dışında bir müşahhaslaştırmaya gidilmez⁹¹³.

Ancak, Kanunda *suçun nitelikli şekli* açısından mağdurun kimliğinin bir unsur olarak tayin edilmesi halinde; mağdurun kimliğindeki yanlış hukukî önemi haiz olacaktır. Meselâ kasten öldürme suçunun “üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı” (m. 82, f. 1, bent d) veya görevi dolayısıyla kamu görevlisine karşı (m. 82, f. 1, bent g) işlenmesi; bu suçun nitelikli şeklini oluşturmakta ve faile daha ağır bir cezanın verilmesini gerektirmektedir.

Bu itibarla; meselâ kişi A'yı öldürmek isterken yanlışlıkla babasını öldürmüş olması halinde, çözüm şu şekilde olmalıdır: Genel olarak bir insanın öldürülmesi veya yaralanması cezaî müeyyide altına alınmıştır. Fail, bir insanı öldürmek veya yaralamak kastıyla hareket etmiştir. Bu itibarla; mağdurun kimliğinde yanlış olsa bile, kasten öldürme veya yaralama suçundan dolayı failin cezaî sorumluluğu cihetine gidilmelidir. Fakat gerçekte öldürdüğü şahıs meselâ babası ise; kasten öldürme suçunun bu nitelikli şekline ilişkin unsur (mağdurun baba olması) açısından failin kastı mevcut değildir. Bu nedenle; failin kasten öldürme suçunun bu nitelikli şekline istinaden cezaî sorumluluğu cihetine gidilmeyecektir.

⁹¹² ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 245.

⁹¹³ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 283.

Kişi, babasını öldürmek isterken, yanlış olarak herhangi bir şahsı öldürmüş olabilir. Kastı her ne kadar babasını öldürmeye yönelik ise de; kişi, gerçekleşen duruma göre, yani herhangi bir şahsı öldürmekten dolayı, cezalandırılacaktır⁹¹⁴,⁹¹⁵.

Bu itibarla, 765 s. Kanunun 52. maddesi hükmüne yeni TCK'nın sisteminde yer verilmemiştir.

C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata

İşlediği fiille ilgili olarak hukuka aykırılık vasfını ortadan kaldıran bir sebebin somut olayda varlığı durumunda, fail bu hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarının gerçekleştiğinin de bilincinde olmalıdır.

Meselâ, a) Meşru müdafaa; müdafaa amacının mevcut olması gerekir (m. 25, f. 1). b) Savunma dokunulmazlığında; mahiyet itibarıyla hakareti mutazammın sözlerin, savunma hakkını kullanmak maksadıyla sarfedilmesi gerekir (m. 128).

Kişi işlediği fiilin esasta bir haksızlık teşkil ettiğinin bilincindedir. Ancak somut olayda hukuka uygunluk sebeplerinden birinin maddi şartlarının gerçekleştiği hususunda yanlışlığa düşmüştür. İşlenen fiilin esasta bir haksızlık teşkil ettiği bilindiği için, suçun kanunî tarifinin ikaz, uyarı fonksiyonu⁹¹⁶ gerçekleşmiştir. Fakat, fail, müşahhas olayda bir hukuka uygunluk sebebinin şartlarının gerçekleştiğini zannetmiştir⁹¹⁷. Hukuka uygunluk sebeplerinin “objektif” olduğu, yani kişinin icra ettiği

⁹¹⁴ “Akrabalarını öldüren KY'nin ailesinden birisini öldürdüklerini zannederek hata sonucu arkadaşları olan ÖC'yi kan gütme saiki ile öldüren sanıklar E ve A ile sanıkları bu suça azmettiren sanık R'nin kastettiklerinin dışında bir kişiyi hata sonucu öldürmüş olmalarından dolayı, 5237 sayılı TCK'nın hata hükümlerinden yararlanmaları ve kasten öldürme suçunun nitelikli halinden değil, **temel şekli**nden sorumlu olmaları gerekmektedir.” CGK, 14.1.2014, E. 2013/1-530, K. 2014/1.

⁹¹⁵ ÖZGENÇ, Süleyman Arslan Armağanı, sh. 350 vd.; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 276 vd. Demirtaş, failin daha az cezayı gerektiren nitelikli halden yararlanabilmesi için, bu durumun olayda gerçekleştiğinin bilincinde olması gerektiği fikrindedir (DEMİRTAŞ, Ankara HBV Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XXV, Temmuz 2021, sh. 390).

⁹¹⁶ Appelfunktion des Tatbestandes. Kavram hakkında bilgi için bkz. JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 290.

⁹¹⁷ Bu durumda, esasen mevcut *bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında yanlış* söz konusudur. Buna karşılık, *bir hukuka uygunluk sebebinin bizzat varlığı* konusundaki yanlış, haksızlık yanlışlığı kapsamında mütalâa edilmelidir (benzer bir değerlendirme için bkz. DÖNMEZER/ERMAN II, no. 699). Meselâ yakalandığı hastalığın verdiği acı ve ızdıraba dayanamayan kişinin ısrarlı talepleri karşısında, ölümünü çabuklaştırıcı ve kolaylaştırıcı bir müdahalede bulunan tabip, bu müdahalenin hukuka uygun olduğu kanaatıyla hareket etmiş olabilir. Bu durumda ancak bir hukuka uygunluk sebebinin bizzat varlığı hususunda bir yanlışlıktan söz edilebilir. Bu itibarla, bu iki yanlışlığı biçimini birbirine karıştırmamak gerekir.

Buna göre; bir kamu görevlisinin yeni yıl veya bir bayram münasebetiyle kendisine verilen hediyeleri kabul etmesinin hukuka aykırı bir yönünün olmadığını zannetmesi, bu kabulü temül normal addetmesi; yine bir haksızlık yanlışlığı olarak mütalâa edilmelidir.

fiil açısından hukuka uygunluk sebeplerinden birinin şartlarının gerçekleştiği hususunda kural olarak bilgi sahibi olmasına gerek olmadığı görüşünün terkedilmesi karşısında; hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarına ilişkin bilginin hangi bağlamda incelenmesi gerektiği doktrinde tartışma konusu olmuştur.

Bu konudaki görüşlerin başında “suçun olumsuz unsurları teorisi”⁹¹⁸ gelmektedir. Bu görüşe göre, suçun kanunî tarifinin fonksiyonu, sadece suça ilişkin maddi ve manevi unsurların belirlenmesinden ibaret değildir. Bu tarif, aynı zamanda fiilin hukuka aykırılık teşkil ettiği hususundaki bütün unsurları da kapsamaktadır. Bu suretle, bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları, suçun olumsuz unsurları olarak mütalâa edilmektedirler. Ancak bu unsurların gerçekleşmemesi halinde işlenen fiil, hukuka aykırılık vasfını haiz olacaktır⁹¹⁹. Bu itibarla, işlenen suç açısından hukuka uygunluk sebeplerinden birinin şartlarının gerçekleşmediği hususundaki bilgi, kasta dahil edilmektedir⁹²⁰. Hukuka uygunluk sebebinin şartlarında yanılğı, suçun unsurlarındaki yanılğı (unsur yanılğısı) ile aynı muameleye tabi tutulmuş olacaktır⁹²¹.

Kusur teorisine mensup yazarlardan bazıları, işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususundaki yanılğı gibi, bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında yanılğıya düşülmesi halinde dahi, bu haksızlık yanılğısının mevcut olduğu fikrindedirler. Bu durumda, işlenen suç açısından kast varlığını devam ettirmekte ve mesele haksızlık yanılğısına ilişkin açıklamalar doğrultusunda çözümlenmektedir⁹²²: *katı kusur teorisi*.

Bir başkasındaki alacağını kanunî yollardan bir türlü tahsil etme imkânı bulamayan şahıs, fırsatını bulduğu bir anda bu kişiden alacağını zorla tahsil etmesi halinde, alacağını tahsile imkân sağlamak amacıyla ve tahsile imkân sağlayacak ölçüde zor kullanmanın hukuka uygun olduğu kanaatiyle hareket etmiş olabilir.

Sanık olarak mahkemede yargılanan kişinin müdafiliğini üstlenmiş olan avukat, sanığın susmasının ve hatta yalan söylemesinin bir “hak” olduğu inancıyla, sanık olan şahsa kendisine isnad edilen suç vakıasına ilişkin olarak mahkeme önünde bir açıklamada bulunmamayı telkin etmesi halinde; bir haksızlık yanılğısına düşmüş kabul edilmelidir.

⁹¹⁸ Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen.

⁹¹⁹ KAUFMANN, Arthur: *Zur Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen*, in: JZ 1954, sh. 653; aynı yazar: *Tatbestand, Rechtfertigungsgründe und Irrtum*, in: JZ 1956, sh. 353, 393; ROXIN, *Offene Tatbestände*, sh. 174 vd.; aynı yazar, *Kriminalpolitik*, sh. 25, dn. 56; aynı yazar, ZStW 76(1964), sh. 582, 599; SAMSON, *Systematischer Kommentar, Vorbem. vor § 32*, kn. 9; TOROSLU, *Ceza Hukuku*, sh. 55 vd. Genel bilgi için bkz. HIRSCH, Hans Joachim: *Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen. Der Irrtum über einen Rechtfertigungsgrund*, 1960, sh. 21 vd.

⁹²⁰ Arth. KAUFMANN, JZ 1954, sh. 653; aynı yazar, JZ 1956, sh. 353, aynı yazar: *Der Irrtum im Strafgesetzentwurf 1962*, in: ZStW 76(1964), sh. 543, 564 vd.; ROXIN, ZStW 76(1964), sh. 582, 599; BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 21, kn. 40.

⁹²¹ Bkz. ÖZGENÇ, *Suçun Yapısında Kusur*, sh. 88 vd.

⁹²² WELZEL, Hans: *Die Regelung von Vorsatz und Irrtum im Strafrecht als legislatorisches Problem*, in ZStW 67(1955), sh. 208 vd.; aynı yazar, *Lehrbuch(11)*, sh. 164 vd.; NIESE,

Doktrinde çoğu yazarlar, esas itibarıyla kusur teorisini benimsemekle beraber, bir hukuka uygunluk sebebinin şartlarının varlığı hususunda yanlışlığa düşülmesi halinde; “suçun olumsuz unsurları teorisi” gibi, kastın varlığından bahsedilmeyeceği görüşündedirler. Bu durumda mesele unsur yanlışlığına ilişkin kurallar doğrultusunda çözümlenecektir⁹²³. Yani, bu yanlışlık halinde artık kastın varlığından bahsedilmeyecek ve dolayısıyla, bu durumda suça şerik olarak iştirak mümkün olmayacaktır: “sınırlı kusur teorisi”.

Kanaatimizce bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında yanlışlığa düşülmesini, işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususundaki yanlışlık ile karıştırmamak gerekir. Haksızlık yanlışlığının söz konusu olduğu hallerde işlenen fiilin maddi oluşumuna ilişkin bütün hususlar bilinmektedir. Fakat bu fiilin toplumda geçerli değerler sistemi açısından bir haksızlık teşkil ettiği hususunda yanlışlığa düşülmektedir. Kısaca ifade edecek olursak; haksızlık yanlışlığı bir *değerlendirme yanlışlığı*ndan ibarettir. Bu itibarla, haksızlık yanlışlığı işlenen fiile ilişkin kastın varlığı üzerinde bir etki icra etmez. Buna karşılık; bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında yanlışlığa düşülmesi halinde; işlenen fiilin esasta bir haksızlık teşkil ettiği bilinmektedir. Fakat, işlenen fiili müşahhas olayda hukuka aykırı olmaktan çıkaran bir maddi sebebin varlığı hususunda yanlışlığa düşülmektedir. Dolayısıyla, burada söz konusu olan yanlışlık, bir maddi vakıya ilişkindir. Bu itibarla; işlenen fiille alâkalı olarak bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları konusunda yanlışlığa düşülmesi halinde; failin bu fiile ilişkin *kastının olmadığı* ve dolayısıyla; meselenin, kusur kapsamında değil, suçun manevi unsuru yani haksızlık kapsamında mütalâa edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmaktayız^{924, 925}.

Werner: *Der Irrtum über Rechtfertigungsgründe*, in: DRiZ 1953, sh. 20; KAUFMANN, Armin: *Tatbestandseinschränkung und Rechtfertigung*, in: JZ 1955, sh. 37; HIRSCH, Negative Tatbestandsmerkmale, sh. 314 vd.; BOCKELMANN, Allgemeiner Teil(3), sh. 129; SCHROEDER, LK(10), § 16, kn. 49, 52; ayrıca bkz. MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 98/99.

⁹²³ GALLAS, Beitrage, sh. 56, dn. 89; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 503; CRAMER, Schönke/Schröder(23), § 16, kn. 14; LENCKNER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. vor § 13, kn. 18; RUDOLPHI, Systematischer Kommentar, § 16, kn. 12. Aynı görüşün değişik ve bazı noktalarda farklı dimansiyonu için bkz. JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 418/419.

⁹²⁴ ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 90/91.

⁹²⁵ Bir hukuka uygunluk sebebinin objektif olarak gerçekleşmesinin esas itibarıyla yeterli olduğu fikrini benimseyen *Dönmezer/Erman*, bir hukuka uygunluk sebebinin şartları konusundaki yanlışlığın “esaslı” olup olmamasına göre bir ayırım yapmaktadır. Buna göre; “eğer fail yanlışlanmış, yani şartlarının gerçekleştiğini zannettiği hukuka uygunluk sebebi fiilen gerçekleşmiş olsa idi, fiil hukuka uygun sayılacak idiyse, yanlışlık esaslıdır; buna karşılık failin gerçekleştiği kanaatında bulunduğu şartlar bilfiil gerçekleşmiş olsa da, ortada hukuka uygunluk sebebi bulunmayacak idi ise, yanlışlık esaslı değildir, fiil hukuka aykırı olmaktan devam eder.” (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 699). Ancak, *Dönmezer/Erman*’a göre, bu “esaslı” yanlışlığın kaçınılmaz (yazarların ifadesiyle, kusurlu) olması halinde dahi, Türk Ceza Kanunu’nda İtalyan Ceza Kanunu’nun 59. maddesinin son fıkrasına benzeyen bir hüküm bulunmaması dolayısıyla, işlenen “fiili hukuka aykırı saymak mümkün değildir”. (1931 İtalyan Ceza Kanunu’nun 59. maddesinin birinci fıkrası hükmü şöyledir: “Fail cezayı bertaraf eden sebeplerin

Bu itibarla, işlediği fiil açısından bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları esasen gerçekleşmediği halde, bu şartların gerçekleştiği zannıyla hareket eden kişinin işlediği suç açısından kastının varlığından bahsedilemez^{926,927,928}.

varlığını hata ile kabul ettiği takdirde, bu sebepler daima onun lehine olarak nazara alınır. Ancak, taksirden doğan bir hata sözkonusu olduğunda, fiil kanunen taksirli bir cürüm olarak öngörülmüşse, cezalandırılabilme bertaraf edilmiş olmaz”).

Buna karşılık; *Kunter*, eğer hukuka uygunluk sebebinin şartlarının gerçekleşmiş olduğu hususunda yanlışlığa düşülmüş ve bu yanlışlığın ortaya çıkışında kendisine herhangi bir kusur yüklenemiyorsa (daha doğrusu, bu yanlışlığı kendisi açısından kaçınılamaz ise); fail, bu hukuka uygunluk sebebinden yararlanır (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sh. 152; ALACAKAP-TAN, Suçun Unsurları, sh. 85/86). *Öztürk* de hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları hususundaki yanlışlığı unsur yanlışlığına ilişkin esaslar çerçevesinde çözümlemektedir (ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 105 vd.).

⁹²⁶ «Mahkeme (sarfedilen) sözlerin savunma çerçevesinde kaldığı ve suç kastı bulunmadığını belirterek, sanığın beraatini karar kılmıştır.

Hakaret ve sövme suçlarında, mağdurun onurunu kırmak bilinç ve iradesiyle davranmaktan ibaret olan suç genel kastının, cürmün oluşması için yeteceği ve dolayısıyla, kullandığı sözcükleri bilerek ve özgür irade ile kaleme alan bir kimsede bu kastın bulunduğu açıktır. Esasen sanık, kullandığı sözcükleri bilincinin ve iradesinin dışında kaleme aldığını da ileri sürmemiştir.

Ayrıca, sanığın savunma çerçevesinde kaldığı ve bu amaçla davrandığı yolundaki gerekçe, teknik ve hukuki ağırlıklı bir kavram olan suç kastını salt psikolojik bir kavram olan amaç ve eylemlerle karıştırdığı ve objektif nitelikteki hukuka uygunluk nedenini sübjektif bir temele yerleştirdiği için de yerinde değildir.»: 4. CD, 19.9.1990, 3748/4259 (YKD Mayıs 1991, sh. 782/783).

Kanunda, hakaret suçlarına ilişkin fasılda hakkın icrası hukuka uygunluk sebebi olarak *savunma dokunulmazlığına* yer verilmiştir (TCK, m. 486). Bu suretle, dava mercilerine verilen dilekçe veya sair evrakın yahut bulunulan iddia ve müdafaaların ihtiva ettiği yazı ve sözler, mahiyetleri itibarıyla hakaret (veya sövme) karakterini arzetseler dahi; savunma çerçevesinde ve bu maksatla kullanıldıkları için, hukuka uygun addedilmektedirler. Bunun için, esas itibarıyla hakaret (veya sövme) niteliğindeki yazı ve sözlerin, iddia veya savunma açısından faydalı olması gerekir ve yeterlidir.

Karardan anlaşıldığı üzere, objektif olarak şartları gerçekleşmemekle beraber; kişi, müşahhas olayda bir hukuka uygunluk sebebi olarak savunma dokunulmazlığına ilişkin maddi şartların gerçekleştiği inancıyla hareket etmiştir.

Esas Mahkemesi, faildeki bu zanna itibar ederek, failin hakaret (veya sövme) suçuna ilişkin kastının olmadığına hükmetmiştir.

Buna karşılık, 4. CD., meselenin sadece objektif yönünü nazarı itibara alarak, esas mahkemesinin görüşüne iştirak etmemiştir.

Görüşümüze göre; bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarındaki yanlışlığı, kişinin ilgili suça müteallik kastını ortadan kaldırır. Bu yanlışlığı, kişi açısından kaçınılabilir bir yanlışlığı olabilir. Böyle bir durumda, ancak ilgili fiilin kanunda taksirle işlenen bir suç olarak tarif edilmesi halinde, failin cezalandırılması mümkündür. Hakaret veya sövme suçu ancak kasten işlenebilen suçlar olduğu için, savunma dokunulmazlığının maddi şartlarındaki yanlışlığının kaçınılabilir olması halinde dahi kişiye ceza vermek mümkün olmayacaktır.

Sonuç olarak, Esas Mahkemesinin görüşüne iştirak etmekteyiz.

⁹²⁷ *Şirin*’in, 3 Nisan 2002 tarihinde düzenlenen bir sempozyumda sunduğu tebliğde sözünü ettiği iki olay, hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında hata ile ilgili ilginç örnekler oluşturmaktadır (ŞİRİN, Osman: *Silah Kullanan Kolluk Görevlileri Hakkında Verilen Yargıtay Kararları*, in: Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, İstanbul 2005, sh. 83 vd.).

Şirin, naklettiği bu olaylardan birincisi şu şekilde cereyan eder:

Kahramanmaraş'ta yakalanan PKK'lı iki terörist, sorgusunda; Doğanşehir, Hekimhan ve Pötürge ilçelerine üç PKK timinin gizlice sızdığını, bunların eylemler yapacağını açıklar. Bunun üzerine kolluk kuvvetleri teyakkuza geçer. Pötürge Tepehan Jandarma karakolunda nöbet tutan er, gece saat 03.30 sularında uzak tepede **yaklaşan bir ışık** görür. Durumdan haberdar edilen Karakoldaki diğer bütün askerler silahlarını ışık istikametini hedef ittihaz ederek siper alır. Bazı beyanlara göre “dur” dendiği halde ışık durmaz, bazı beyanlara göre de “dur” denmeden “**PKK'lılar geldi**” **düşüncesiyle ışık istikametine doğru seri atışlar** yapılır. Yapılan atışlar sonucunda ışık ve hareket kesilir. Gün ağardığında yapılan kontrolde, **iki yaşlı kişinin cesediyle** karşılaşılır. Bunların, **bayram namazı kılmak üzere** karakol yakınındaki **camiiye gelen iki köylü** olduğu anlaşılır.

Bu olayda *Şirin*'in verdiği bilgiye göre, Yerel mahkeme, (mülga 765 s. TCK'nın) 450/5 maddesiyle, 463 ve 50. maddeleri uyarınca sanık jandarmaları mahkum eder. Ancak, Yargıtay 1. CD, Jandarma Teşkilat Nizamnamesinin 27. maddesi ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanununun 87, 4/2 ve 6. maddeleri gereğince, sanık jandarmaların **kanunun hükmünü icra** ettiğini ve dolayısıyla, fiillerinin **hukuka uygun** olduğunu; olayda zaruret hududunun da aşılmadığını kabul ederek, hükmü bozar.

Dikkat edilmelidir ki, bu olayda bir **saldırı** durumu **söz konusu değildir**. Dolayısıyla, bir **hukuka uygunluk sebebinin varlığından söz edilemez**. Ancak, görevli jandarmalar, kendilerine yönelik bir saldırının gerçekleşmekte olduğunu zannetmişlerdir. Dolayısıyla, olayda **bir hukuka uygunluk sebebi olan meşru savunmanın maddi şartlarında hataya** düşülmüştür. Bu hata, sanık jandarmaların kasten öldürme suçunu işleme bakımından kastını ortadan kaldırmaz. Ancak, kanımızca, bu hata **kaçınılabılır** bir **hatadır**. Bu nedenle, söz konusu olayda sanıkların **taksirle öldürme** suçundan dolayı sorumlulukları cihetine gidilmek gerekirdi.

Yerel mahkeme bu olayda önce kasten adam öldürme suçundan dolayı mahkumiyet kurmuştur. Ancak, birden fazla kişi öldüğü için 765 s. TCK'nın 450. maddesinin (5) numaralı bendine istinaden cezaya hükmetmiştir. Olayda pek çok jandarma birlikte ışık istikametine doğru silahla ateş etmişlerdir. Ölen yaşlı kişilere hangi jandarma erlerinin tüfeğinden çıkan kurşunların isabet ettiği tespit edilemediği için (?), her bir jandarmanın cezasında 765 s. TCK'nın 463. maddesine istinaden indirim yapılmıştır. Ayrıca Yerel Mahkeme olayda **hukuka uygunluk sebebinde sınırın taksirle aşıldığını** kabul ederek, 765 s. TCK'nın 50. maddesine istinaden bu cezadan da indirim yoluna gitmiştir.

Yerel mahkemenin bu olayda mülga 765 sayılı TCK'nın 463. maddesi hükmünü uygulaması, bu maddenin ne kadar yanlış bir içeriğe sahip bulunduğu anlaşılması bakımından bir örnek oluşturmaktadır.

Olayda bir **hukuka uygunluk sebebinin sınırının aşılması söz konusu değildir**. Sınırın aşıldığı hallerde esasen olayda bir hukuka uygunluk sebebi mevcuttur. Ancak, 765 sayılı mülga TCK'nın sisteminde hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında hataya düşmeye ilişkin hüküm bulunmadığı için; sorun, hukuka uygunluk sebebinde sınırın aşılmasına ilişkin 50. madde ile bağlantılı olarak çözümlenmeye çalışılıyordu.

Bu bağlamda **taksirin** varlığının kabul edilmesi ile Yerel Mahkeme tarafından kısmen doğru bir karar verildiği söylenebiliriz.

Şirin'in naklettiği diğer bir olay ise şu şekilde cereyan eder:

Ordu Ağır Ceza Mahkemesinin hükmüne bağladığı olay, 23 Ağustos 1997'de Mesudiye İlçesinde gerçekleşir. PKK terör örgütünün Karadenize iniş hazırlığında olduğu, bölgede terörist faaliyetlerde bulunduğu, bazı karakolların basıldığı gerekçesiyle, Ordu Emniyeti Özel Harekat Timi bölgede görev yapar. Olay akşamı, karanlığın yeni çıktığı sisli bir ortamda üç araba halinde Mesudiye İlçesinin Güneyce Köyüne girilir; araçların ışıkları söndürülür. Son araç zırhlı ve üstten projektörlüdür. Ortadaki araçta, elleri silahlı olarak, yüzleri dışa dönük biçimde se-

30. maddenin üçüncü fıkrasında her ne kadar “*ceza sorumluluğunu kaldıran ... nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda ... hata*”dan söz edilmişse de; yeni TCK’nın sisteminde gerek hukuka uygunluk nedenleri gerek kusurluluğu etkileyen nedenler “*Ceza sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler*” başlığıyla aynı bölüm (Birinci Kitap, İkinci Kısım, İkinci Bölüm) altında düzenlenmiş olduğu için, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hatayı da bu fıkra kapsamında değerlendirmek gerekir.

Buna karşılık, işlediği fiil açısından bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları objektif olarak gerçekleşmiş olmasına rağmen, fail bu şartların gerçekleşmiş olduğunun farkında değildir. Bu durumda, her ne kadar bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları objektif olarak gerçekleşmiş ise de; faili, kanaatimizce, işlediği fiilin ilişkin olduğu suça teşebbüsten dolayı sorumlu tutmak gerekir. Zira, böyle bir durumda objektif olarak hukuka uygunluk sebebi mevcuttur. Dolayısıyla, neticenin haksızlığından bahsetmek mümkün değildir. Ancak, kişi hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarının gerçekleştiği bilinciyle hareket etmediği için, fiilin haksızlık olarak gerçekleştiğini kabul etmek gerekecektir⁹²⁹.

yahat eden biri komiser altı polisten birisi dışarıda bir hareketlenme sezinler ve “galiba baskına uğradık” der. Bu söz üzerine, **tarladan yola yaklaşan, ellerinde elektrikli fenerler bulunan iki insan silüetine** doğru önce otonun içinden, bilahare aşağıya atlanılarak yol kenarındaki siperden, **226 mermi** atılır. ... Atışların devamı sırasında, arkadaki zırhlı araçtan “ateşi kesin, onlar çocuk” bağırtısı duyulduğunda ateşe son verilir. Bakıldığında, biri **onüç yaşında** Turgay, diğeri **onaltı yaşında** Cihat isimli **iki çocuk** oldukları ve çobanlık yapan bu çocukların dedelerinin evinden babalarının evine giderken kurşunlandıkları anlaşılır. Turgay’a **on mermi**, Cihat’a **sekiz mermi** isabet eder. ... **Sanıklar, kendilerine dışarıdan herhangi bir atış yapılmadığını**, yanlış ile ve içinde bulundukları endişeli ortamın sonucu ateş etmek zorunda kaldıklarını savunurlar.

Şirin’in naklettiğine göre, Yerel mahkeme, sanıkların yanlışısının makul bulunduğunu, ortam ve içinde bulunulan **terör korkusu** karşısında, **sanıkları davranışlarında hukuka aykırılık olmadığını**, öldürme eylemlerinin (mülga 765 s.) TCK’nın 452/1, 463. maddelerine uygun, ancak, 49/1. maddesinde düzenlenen **kanunun hükmünü icra hukuka uygunluk sebebi** kapsamında gerçekleştiğini kabulle, sanıklar hakkında ceza tertibine yer olmadığına hükmetmiştir.

Saldırının bulunmadığı bu olayda da bir hukuka uygunluk sebebinin varlığından söz edilemez.

⁹²⁸ Türk hukuk doktrininde *Keçelioğlu*, bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında hataya düşülmesi halinde, ceza sorumluluğuna ilişkin sorunun **kusur teorisi**yle çözümlenmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte, *katı kusur teorisine* taraftar olduğunu açıklamaktadır: KEÇELİ-OĞLU, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 87 (Mart – Nisan 2010), sh. 315.

⁹²⁹ ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku(2), sh. 111 vd. Bu durumda da tamamlanmış suçtan dolayı cezaya hükmedilmesi gerektiği yönündeki görüşler için bkz. DURSUN, Selman/BOZBAYINDIR, Ali Emrah: *Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Manevi Unsurları Meselesi*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LXXIII, yıl 2015, sayı 1, sh. 63 vd. (78 vd.). Buna karşılık, hukuka uygunluk sebeplerinin objektif bir vasıf taşıdığını kabul eden yazarlar ise, kişinin somut olayda bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarının gerçekleştiğinden haberi olmasa bile, hakkında cezaya hükümlenemez görüşündedirler (DURSUN/BOZBAYINDIR, sh. 80 vd., 86 vd.).

Hukuka uygunluk sebebinin şartları tanımlanabilir veya değerlendirilebilir nitelik arzettiği için; bu yanılğı, her iki türden şartlar açısından da söz konusu olabilir.

Hukuken geçerli rızanın arandığı durumlarda rıza beyanında bulunan kişinin algılama yeteneğini haiz olduğu, yani beyan ettiği rızanın hukuki sonuçlarını kavrama yeteneğinin gelişmiş olduğu hususunda yanılğıya düşülmesi halinde; işlenen suç açısından artık kastın varlığından bahsedilemez^{930 931}.

Bir saldırıya uğrayan kişinin, saldırının yoğunluğu konusunda yanılğıya düşmesi sonucu meşru müdafaa için gerekli savunma sınırını aşması halinde, hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında yanılğıya düşmüş demektir⁹³².

Hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarındaki hatanın, failin içinde bulunduğu koşullar bakımından kaçınılmaz olması halinde, cezaya hükmolunmaz.

Bu yanılğının kaçınılabilir olup olmadığının tayini, taksirle işlenen haksızlıklar açısından söz konusu olan dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâline ilişkin ölçütler doğrultusunda yapılacaktır⁹³³.

⁹³⁰ BGH, 2. Strafsenat, 28.10.1955 (BGHSt 8[1956], sh. 357 vd. [358]); BGH, 5. Strafsenat, 10.2.1959 (BGHSt 12[1959], sh. 379 vd. [383]).

⁹³¹ «Sanık, eşinin rıza göstereceğine inandığı için, ihtiyaç duydukları parayı onun imzasını taklit ederek bankadan çekmiştir.

Sanığa usulüne uygun bir ödeme yapılmadığı bizzat ilgili banka şubesi yetkililerince de kabul edilmektedir. Söz konusu hesapta müdahilin tatbik ve mukayeseye elverişli imzası yoktur. Buna rağmen ibraz ettiği yazıya dayanarak sanığa ödeme yapılmıştır. (Bu nedenle) banka şubesinin dolandırılması söz konusu değildir.»: CGK., 10.6.1985, 56/340 (Savaş/ Mollamahmutoğlu I, sh. 553/554).

«Sanı(k), (müşteki ve aynı zamanda müdahil olan şahsın) oturduğu evin sahibi(dir) ve aynı çatı altında diğer (bir) dairede kendisi ikamet et(mektedir.) Müştekillerin oturduğu kısım duvarlarında rutubet dışarıya vurunca, su borularındaki patlama ihtimali ve böylece binanın tahribini önlemek için; bir defasında evde olan müdahilin muvafakatı ile; sanı(k), getirdiği usta ile birlikte eve girerek, arıza mahiyetini öğren(miştir.) Tamir için ikinci defa başka bir usta ile gel(en sanık,) esasen memur olan müşteki ve eşinin evde bulunmadıklarını görünce, aralarında ilişkiler ve evvelce de aynı maksatla girmesine güvene(rek, bir başka anahtarla kapıyı açmış ve) getirdiği bu usta ile eve gir(miştir)... Eve gir(il)diğini akşam (üzeri) öğrenen müdahil, sanığın eşi ile bu konuda tartış(miştir.) ... (Sanık,) ertesi sabah dairesine kadar gide(rek), müdahilin eşine eve girmeğe mecbur kaldığını izah et(miştir). (Bu durum karşısında; sanığın kastının,) evini tamir etmeye matuf (olduğu ve dolayısıyla,) mesken masuniyetini ihlâl olmadığı anlaşılmaktadır.»: CGK., 31.3.1975, 53/72 (Savaş MollamahmutoğluI, sh. 573).

⁹³² BGH, 1. Strafsenat, 1.6.1952 (BGHSt 3[1953], sh. 194 vd.[196]).

⁹³³ “Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 7.11.2019 tarihli ve E. 2018/27, K. 2019/644 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; şehir merkezine uzaklığı nedeniyle zaman zaman hırsızlık olaylarının meydana geldiği sitede oturan A, eşi B ile birlikte yatak odasında uyumakta iken sabaha karşı saat 4.00 sularında “dışarıdan sızan ışığın etkisi ile alaca karanlık olan yatak odası penceresinden ses geldiğini duyması üzerine, tedbir amacıyla yastığının altında muhafaza ettiği yarı otomatik tabancasını perde ile kapatılmış pencereye doğrultarak yaklaşık 4 metre mesafeden 13 kez tetiğe basarak silahının şarjöründe bulunan 13 mermimin hepsini tek tek ateşle”r. Gece uykusu kaçan ve pencereden dışarıyı seyreden eşi B, bu atışlardan aldığı yaralar sonucu ölür.

Bu yanılmanın *kaçınılabılır* olması halinde; şayet söz konusu fiilin taksirle işlenmiş olması kanunda müstakil bir suç olarak tanımlanmış ise; fail ancak taksirinden dolayı cezalandırılabilir.

II. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri

A. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata

Kusurluluğu etkileyen nedenler, *kusurluluğu kaldıran* veya *azaltan* nedenler olarak ikiye ayrılırlar⁹³⁴.

Somut olayda, kusurluluğu kaldıran veya azaltan bir nedenin maddi şartlarında hataya düşmesi halinde, kişi bu hatasından yararlanır. Bu hata, kusurluluk bağlamında mütalaa edilmelidir (m. 30, f. 3).

Kişi, somut olayda kusurluluğu kaldıran neden olarak örneğin zorunluluk halinin koşullarında, tehdidin ya da hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin varlığı hususunda hataya düşmüş olabilir. Bu yanılmanın kişi açısından *kaçınılmaz* olması halinde, işlediği fiil açısından kusurunun varlığından söz edilemez. Dikkat edilmelidir ki, bu gibi durumlarda somut olayda kusurluluğu kaldıran bir

Ceza Genel Kurulu, aşağıdaki gerekçe ile, bu olayda A'nın **hatasının kaçınılabılır** olduğu ve dolayısıyla, bu hatasından yararlanamayacağı yönünde içtihatla bulunmuştur:

“eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan sanığın, etrafı duvarla çevrili sitede bulunan 3 katlı müstakil evinin birinci katında yer alan yatak odasında, eşi maktul ile bulunduğu sırada, pencereden ses gelmesi üzerine, yanında yatan eşi maktulün yatakta bulunup bulunmadığını kontrol etmek, ışığı açarak odayı aydınlatmak, işittiğini belirttiği sesin geldiği yöne seslenmek gibi basit bir dikkat veya özenli davranış göstermiş olması durumunda, kendisine yönelmiş bir saldırının bulunmadığını anlayabilecek durumda olmasına karşın, herhangi bir uyarıda bulunmadan, dışarıdan sızan ışığın etkisi ile alaca karanlık olan yatak odasında, yastığının altında muhafaza ettiği yarı otomatik tabancayı eline alıp 13 kez ateşleyerek yaklaşık 4 metre mesafedeki maktulü her biri öldürücü nitelikte 3 isabetle yaralayarak öldürmüş olması karşısında; sanığın daha dikkatli ve özenli davranması durumunda ateş ettiği kişinin, kendisine yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırı içindeki bir hırsız olmadığını anlayabileceği, bu nedenle **sanığın bu hatasının kaçınılmaz nitelikte bir hata olmadığı**, sanığın TCK'nın 30. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususundaki hata hükmünden yararlanamayacağı kabul edilmelidir.”

Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu olayda A'nın hatasının kaçınılabılır olduğu yönündeki kabulü doğrudur. Ancak, bu kararda olayla ilgili olarak yapılan hukuki değerlendirmelerde önemli bir eksiklik bulunmaktadır. Bu içtihatla, izah biçimi itibarıyla, A'nın ateş ettiği şahsın gerçekte hırsız olması durumunda ceza sorumluluğunun olmayacağının kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ancak, bu durumda, A'nın hangi sebeple ceza hukuku sorumluluğunun olmayacağının tartışma konusu yapılmaması, önemli bir eksikliktir. Kararda konunun öncelikle, A'nın ateş ettiği şahsın gerçekte hırsız olması durumunda meşru savunmada sınırın korku, telaş ve heyecan sebebiyle aşılması bağlamında TCK, m. 27, f. 2 hükmü çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulması gerekirdi.

⁹³⁴ Keçelioğlu, bu bağlamda sadece “kusurluluğu ortadan kaldıran sebepler” ibaresini kullanmaktadır: KEÇELİOĞLU, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 87 (Mart – Nisan 2010), sh. 299 vd.

neden olarak örneğin zorunluluk hali mevcut değildir. Ancak, kişi zorunluluk halinin şartlarının gerçekleştiği hususunda yanılgıya düşmüştür. Bu yanılgının kaçınılmaz olması halinde, bu nedenle, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Buna karşılık, kişi, somut olayda *kusurluluğu azaltan neden* olarak örneğin haksız tahrikin koşullarında hataya düşmüş olabilir. Somut olayda haksız tahrikin maddi şartları gerçekleşmemiştir, yani örneğin işlenmiş bir haksız fiil bulunmamaktadır. Ancak, kişi gerçekleşmiş olduğunu zannettiği haksız bir fiilin kendisinde oluşturduğu öfke halinin etkisiyle bir suç işlemiştir. Bu yanılgının kişi açısından *kaçınılmaz* olması halinde, haksız tahrik hükümlerine istinaden, hakkında hükmolunacak cezada indirim yapılır.

Kusurluluğu kaldıran veya azaltan nedenlerin maddi şartlarında hatanın *kaçınılabılır* olması halinde; kişi cezalandırılacaktır; fakat cezasında, ancak alt sınıra kadar indirim yapılabilir⁹³⁵,⁹³⁶.

⁹³⁵ “Ceza sorumluluğunu azaltan nedenlerden olan haksız tahrikin varlığı konusunda da hataya düşülebilir. Haksız tahrikin varlığı konusunda kaçınılmaz hataya düşen fail haksız tahrik hükmünden yararlanacaktır. Fakat burada hatanın kaçınılmaz olması zorunludur. Buna karşılık, hata kaçınılabılır bir hata ise, yani failin kişisel özellikleri göz önüne alındığında, daha dikkatli ve özenli davranması durumunda hatasından kaçınılabilecekse başka bir anlatımla hata meydana gelmeyecekse artık haksız tahrik hükümlerinden yararlanamayacaktır.

...

Somut olayda, öldürmeyi düşündüğü Kamuran tarafından eşi kaçırılan sanığın haksız bir eylemin etkisiyle hareket ederek eylemi gerçekleştirdiği konusunda bir tereddüt bulunmamakta ise de, sanığın eylemini eşinin kaçırılmasının üzerinden bir yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra gerçekleştirmiş bulunması, daha önce eşini kaçırarak Kamuran'ı bir kez görmüş olması ve Kamuran ile maktul arasında 6 yaş farkın bulunması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın daha dikkatli ve özenli davranması durumunda öldürdüğü Cahit'in gerçek kimliğini anlayabileceği, bunun için de somut olay itibarıyla yeterli zamanının olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, **sanığın hatası kaçınılmaz nitelikte bir hata olmadığından**, dolayısıyla sanığın hata hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmadığından, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerini uygulayan yerel mahkeme kararının bozulmasına ilişkin Özel Daire kararı isabetlidir.” CGK, **24.12.2013**, E. 2013/1-664, K. 2013/622.

⁹³⁶ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **15.3.2016** tarihli ve E. 2014/3-436, K. 2016/134 sayılı kararına konu teşkil eden olayda, F, baldızının oğlu olan ve kendisinden 34 yaş küçük M ile birlikte denizde yüzerler. Bu sırada M, F’ye, “köpek stili yüzüyorsun, köpek yüzüşü yapıyorsun” der. F, bu ifadeyi kendisine hakaret olarak değerlendirir. Aile bireylerinin, bu sözü yanlış anladığını, M’nin hakaret kastının olmadığını F’ye söylemesine rağmen, F, bu sözün etkisiyle M’yi bıçakla yaralar.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıdaki gerekçelerle F hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması yönünde içtihatla bulunmuştur:

“bu sözleri yanlış anlayan ve kendisine köpek denildiğini düşünen sanığın, katılanın ailesinin araya girerek kendisine hakaret edilmediğine ilişkin açıklamalarına rağmen, ... yanına aldığı ekmek bıçağı ile ... katılanı ... bıçakla ... yaraladığı ... olayda, katılanın herhangi bir suç işleme kastı taşımadan söylediği beğeni ifade eden, literatürde “köpekleme yüzme stili” olarak da bilinen, başın dışarıda tutulup, su içerisinde koşmaya benzeyen ve zor öğrenilen bir yüzme şekli olan “köpek stili yüzüyorsun” biçimindeki sözlerin hakaret vasfı içermediği gibi, kişilerin

B. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata

Kusurluluk açısından önemli olan, kişinin, işlediği fiilin hukuken tasvip edilmez bir fiil olduğunun bilincinde olmasıdır⁹³⁷. Ancak, işlenen fiilin pozitif hukuk metinlerinde cezalandırılabilir bir fiil olarak, yani suç olarak tanımlanmış olduğunu bilmek gerekmez. Hatta, işlenen fiilin bir haksızlık teşkil ettiğinin bilincinde olduktan sonra; ayrıca cezaya layık bir haksızlık⁹³⁸ olduğunun bilinip bilinmediğinin araştırılmasına gerek yoktur⁹³⁹,⁹⁴⁰. Bu hususla ilgili olarak kusurluluğun iki unsurundan birini oluşturan algılama yeteneğine ilişkin açıklamaları-mıza bakılmalıdır⁹⁴¹.

onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte de olmadığı, bu durum karşısında sanığın, eşinin yeğeni olan, aralarında önceye dayalı başkaca bir sorun ya da husumet bulunmayan, ... olay tarihi itibarıyla onsekiz yaşında bulunan katilani bıçakla ... kasten yaralama eylemini, katılanın söylediği sözlerin, dolayısıyla katulandan kaynaklanan haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ya da şiddetli elemin etkisi altında kalarak gerçekleştirdiğini kabule imkân bulunmamaktadır.”

Karara konu teşkil eden olayda M'nin sarf ettiği sözlerin hakaret mahiyeti taşımadığı kuşkusuzdur. Ancak F, bu sözle kendisine hakaret edildiğini düşünmüştür. Bu nedenle F, haksız tahrikin maddi şartlarından biri olan haksız fiilin varlığı hususunda hataya düşmüştür. Şayet bu hatası kaçınılmaz ise; TCK, m. 30, f. 3 hükmü gereğince, F'nin bu hatasından yararlanması ve hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekir. Ancak, olayda F'ye aile bireyleri tarafından M'nin bu sözle kendisine hakaret etmediği, M'nin böyle bir kastının olmadığı müteaddit defa beyan edilmesine rağmen, F'nin bu değerlendirmesinde ısrar etmesi, bu hatasının kaçınılmaz olmadığını göstermektedir.

Sonuç itibarıyla doğru olsa bile, Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararında TCK, m. 30, f. 3 hükmünün göz ardı edilmesi, önemli bir bilgi eksikliğine işaret etmektedir.

⁹³⁷ JAKOBS, Lehrbuch(1), § 19, kn. 23 vd.; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 408 vd.; aynı yazar, Ceza Hukuku, sh. 29/30; MAURACH/ZIPF I, sh. 524 vd.; BLEI, Allgemeiner Teil, sh. 198 vd.; KAUFMANN, Arthur: *Das Unrechtsbewußtsein in der Schuldlehre des Strafrechts*, 1950, sh. 142 vd; aynı yazar, *Das Schuldprinzip*, sh. 130 vd.; BEHRENDT, sh. 49.

⁹³⁸ Strafwürdiges Unrecht.

⁹³⁹ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 214 vd.; MAURACH/ZIPF I, sh. 524/525; WESSELS(19), sh. 120; SÖZÜER, YD 21(1995), sh. 479 vd.; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 9. bası, sh. 50.

⁹⁴⁰ “Kanun metninin bilinip bilinmemesi değil, gerçekleştirilen davranışın esasen bir haksızlık teşkil ettiğinin bilinmesi ceza sorumluluğu açısından önemlidir. Bu bakımdan, kişi gerçekleştirdiği davranışın esasen bir haksızlık oluşturduğunun bilincinde olmasına rağmen, bu davranışın kanunlarda suç olarak tanımlanmış olduğunu bilmese dahi, ceza hukuku bakımından sorumluluğu yoluna gidilir. Bu(na karşılık) işlediği fiilin esasen haksızlık teşkil ettiğini bilmeyen kişiye ceza verilmez; ancak, bu hatanın kaçınılmaz olması gerekir.” (TBMM Adalet Komisyonunun 30.6.2004 tarihli toplantısında yeni TCK'nın 4. maddesine ilişkin olarak yapmış bulunduğu açıklama).

“... Burada sorun, kanunun bilinip bilinmemesiyle ilgili değildir. ... kanunu bilip bilmemenin ceza sorumluluğuyla esasında bir ilgisi yoktur.” (Adem SÖZÜER'in, TBMM Adalet Komisyonunun 30.6.2004 tarihli toplantısında yeni TCK'nın 4. maddesine ilişkin olarak yapmış bulunduğu açıklama).

⁹⁴¹ ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 230.

Kişi, işlediği fiilin *maddi hukuka*⁹⁴² aykırılık arzettiğini bilememiş olabilir. Bu durumda *haksızlık yanılığı*⁹⁴³ mevcuttur⁹⁴⁴. İşlenen fiilin hukuka aykırı olduğunun bilinmemesi halinde, haksızlık teşkil eden fiil açısından kişinin kastı varlığını devam ettirir. Bir başka ifadeyle; haksızlık yanılığı, kasta etkili olan bir husus olmayıp; kişinin işlediği haksızlık açısından sadece kusurunun belirlenmesinde bir rol oynamaktadır⁹⁴⁵.

Ancak, Yargıtay, haksızlık yanılığının söz konusu olduğu olaylarda, sorunu kast kapsamında mütalaa ederek çözüme yoluna gitmiştir. Yani, 765 s. TCK'nın 44. maddesi hükmüne rağmen, Yargıtay, kast olmadığından söz ederek bu konulara ilişkin çözüm oluşturmuştur⁹⁴⁶:

“Seçim bittikten sonra muhafazası lazım gelen oy pusulalarını sanığın yakmasının, lüzum kalmadığı yolundaki kanaatinden ileri geldiğini müdafaa beyan etmesine göre; bu müdafaa hilâfında kastı cürmü takip ettiği hakkındaki sübut delilleri gösterilmeksizin mahkûmiyet kararı verilmesi” hukuka aykırıdır⁹⁴⁷.

Soyut olarak haksızlık yanılığından söz edilemez. Ancak belli bir fiilin haksızlık teşkil edip etmediği hususunda bir yanılığın varlığından söz edilebilir. Kişi ancak işlediği somut fiilin hukuka aykırı olduğunun, bir haksızlık teşkil ettiğinin bilincinde olmayabilir.

Haksızlık yanılığının kişi açısından kaçınılmaz olması halinde, kişiyi gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla muaheze etmemekteyiz. Bir başka ifadeyle, bu halde kişiyi kusurlu addetmemekteyiz. Ancak, işlenen fiilin haksızlık teşkil etti-

⁹⁴² “Maddi hukuk” kavramıyla kastettiğimiz, pozitif hukuk düzenlemeleri olmayıp; toplumda geçerli olan değerler sistemidir. Bu itibarla, işlenen fiilin toplum düzeninin gereklerine aykırılık arzettiğinin ve bu nedenle, tasvip edilmez olduğunun bilinmesi yeterlidir. İşlenen fiilin ayrıca pozitif hukuk metinlerinde yasaklanmış bir fiil olduğunun bilinmesine gerek yoktur. Bu açıklamalarımız nazarı itibara alındığında, yukarıda izah ettiğimiz *kusur teorisi*ne taraf olduğumuz açıkça anlaşılacaktır.

⁹⁴³ Verbotsirrtum.

⁹⁴⁴ Bu arada hemen ifade etmemiz gerekir ki; “*kanaat suçlusu*” diye tavsif edilen şahıs; şayet işlediği fiil ile ihlâl ettiği davranış normunun toplumda kabul görmüş, geçerli bir kural olduğunu biliyor idiyse; şahsen farklı bir kanaate, inanca sahip olmasına rağmen; bu fiilin bir haksızlık teşkil ettiğinin bilincindedir. Buna karşılık, kişi; şayet işlediği fiille içinde yaşadığı toplumda geçerli bir davranış normunu ihlâl ettiğini bilmiyor idiyse; haksızlık bilincinin mevcut olmadığını kabul etmek gerekir (JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 408 vd.; WELZEL, Lehrbuch(11), sh. 176 vd.; RUDOLPHI, Systematischer Kommentar, § 17, kn. 4).

⁹⁴⁵ Bu husus, söz konusu madde gerekçesinde açık bir şekilde vurgulandığı gibi; 1997 Öntasarısının 2. maddesinin gerekçesinde de, haksızlık yanılığı “*kusuru kaldıran bir sebep*” olarak mütalaa edilmiştir.

⁹⁴⁶ Bkz. TBMM Adalet Komisyonunun 30.6.2004 tarihli toplantısında söz konusu 4. maddeye ilişkin olarak yapmış bulunduğumuz açıklama.

⁹⁴⁷ 3. CD, 18.1.1951, 10370/234 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 577).

ği hususunda düşülen yanlışın kaçınılabilir olması halinde, kusurun azalmış olabileceğini kabul etmek gerekir. Yanılgıya rağmen işlenen fiil, *kasten işlenmiş bir fiildir*⁹⁴⁸.

Kast teorisi, yukarıda açıkladığımız gibi, işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususundaki bilgiyi kasta dahil etmektedir. Buna göre, işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiğinin bilinmemesi halinde, artık kastın varlığından bahsetmek mümkün olmayacaktır; yani, ortada taksirle işlenmiş bir fiil vardır. Bu fiilin ancak kanunda suç olarak tanımlanmış olması halinde failin cezalandırılması mümkündür olacaktır. Aksi takdirde, fail cezasız kalacaktır⁹⁴⁹: *katı kast teorisi*.

Kast teorisinin ortaya çıkardığı cezasızlık halini gidermek için çeşitli çözüm yolları önerilmiştir. Birinci yol olarak; haksızlık yanlışının kapsamının daraltılması suretiyle, bu cezaî boşluğun alanının daraltılması istenmiştir. Yani, hukuk düzeni açısından tamamen alâkasız davranmak veya hukuk düzenine düşmanlık beslemek dolayısıyla işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususunda yanlışla düşülmüş ise, bu yanlışın bir önemi olmayacaktır; kişi işlediği fiilden dolayı kasten sorumlu tutulacaktır⁹⁵⁰. Diğer bir çözüm şekline göre ise, kanunda yeni bir suç tipi ihdas edilmelidir. “*Hukuki taksir*”le⁹⁵¹ işlenen bütün fiiller bu suretle cezalandırılmış olacaktır⁹⁵².

Kast teorisine yöneltilen eleştirilerin odağını bu teorinin suçun unsurlarındaki yanlış ile haksızlık yanlışını aynı işleme tabi tutması oluşturmaktadır. Halbuki unsur yanlışlığı bir maddi vakiya ilişkindir. Buna karşılık, haksızlık yanlışlığı, bir değerlendirme yanlışlığından kaynaklanmaktadır. Keza, kast teorisi, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir cezaî boşluk meydana getirmektedir⁹⁵³.

Gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla kişinin cezalandırılabilmesi için işlediği fiilin bir haksızlık teşkil ettiğini gerçekten, reel olarak, aktüel olarak bilmesi gerekmez. Kişi, her ne kadar işlediği fiilin haksızlık teşkil ettiğini hakikaten bilmiyorsa da, sahip olduğu akletme yeteneği, gördüğü eğitim, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevre itibarıyla bu fiilin bir haksızlık teşkil ettiğini kavrayabilecek durumda olabilir. İşlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususundaki yanlışın kaçını-

⁹⁴⁸ HORN, Eckhard: *Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit. Eine systematische Grundlagenanalyse der Schuldtheorie*, 1969, sh. 56 vd.; TOROSLU, Ceza Hukuku, sh. 141, 143.

⁹⁴⁹ SCHMIDHAEUSER, Lehrbuch, § 4, kn. 10, 25, 26, § 7, kn. 36, 42, (kastla alâkalı olarak) 68 vd., (taksirle alâkalı olarak) 102 vd.; SCHÖNKE/SCHRÖDER(17), § 59, kn. 76 vd.; BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 20, kn. 31, 40, § 21, kn. 40.

⁹⁵⁰ Eingeschraenkte Vorsatztheorie: MEZGER, *Moderne Wege*, sh. 43 vd.; aynı yazar, *Rechtsirrtum und Rechtsblindheit*, in: *Festschrift für E. Kohlrausch*, 1944, sh. 183 vd.

⁹⁵¹ Rechtsfahrlaessigkeit.

⁹⁵² 1936 Alman Ceza Kanunu Tasarısı, § 16, II, 2.

⁹⁵³ WELZEL, *Aktuelles Strafrechtsprobleme*, sh. 10 vd.; aynı yazar, Lehrbuch(11), sh. 159 vd.; MAURACH, Lehrbuch(4), sh. 458 vd.; ROXIN, Claus: *Die Behandlung des Irrtums im E.1962*, in: *ZStW* 76(1964), sh. 582 vd. (604); JESCHECK, Lehrbuch(2), sh. 344.

labilir olup olmadığının tayini hususunda, taksirle işlenen haksızlıklarla alâkalı olarak failin kusur muhtevasının belirlenmesindeki metod izlenmelidir.⁹⁵⁴

Taraf olduğumuz⁹⁵⁵ *kusur teorisine* göre; haksızlık yanılığının kaçınılabilir olduğu bu durumlarda da kişi gerçekleştirdiği fiil açısından kasten hareket etmiştir⁹⁵⁶. Ancak, düştüğü bu yanılığın kaçınılabilir olması nedeniyle, kusurunun azalmış olabileceğini kabul etmekteyiz⁹⁵⁷. İşlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususundaki bilginin azalmasından bahsedilemez. Kişi, işlediği fiilin bir haksızlık teşkil ettiğini ya bilmektedir veya bilmemektedir. Şayet kişi, işlediği fiilin haksızlık teşkil ettiğini bilmiyor ise; o zaman bu yanılığın kaçınılabilir olup olmadığı araştırılacaktır. Bu yanılığın kaçınılabilir olduğunun kabul edilmesi halinde, bu kaçınılabilirliğin derecesine göre kusurun da derecelendirilmesinden bahsedebiliriz. Bu durum, kişinin işlemiş bulunduğu suçtan dolayı temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınacaktır^{958, 959}.

⁹⁵⁴ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 412/413; MAURACH/ZIPF I, sh. 534; CRAMER, Schönke/Schröder(23), § 17, kn. 12; RUDOLPHI, Systematischer Kommentar, § 17, kn. 30a.

⁹⁵⁵ ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 85 vd.; ÇINAR, Ön kusurluluk, sh. 61.

⁹⁵⁶ *Toroslu/Ersoy*, hata müessesesinin teorik gelişiminden habersiz oldukları için, hatanın kaçınılmaz olması ile ilgili olarak Kanun metninde “kusursuz hata” ibaresinin kullanılmasının daha yerinde olacağını iddia etmektedirler (TOROSLU/ERSOY, sh. 12. Ayrıca bkz. HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 228).

⁹⁵⁷ SÖZÜER, YD21(1995), sh. 478.

⁹⁵⁸ *Ünver*, yeni TCK’nın 30. maddesine eklenen dördüncü fıkranın gerekçesinde yer alan işlenen fiilin haksızlık oluşturduğu hususundaki “*hatanın kaçınılabilir olması durumunda kişi kusurlu sayılacak ve bu husus, temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.*” şeklindeki açıklamayı eleştirmektedir (ÜNVER, Ceza Hukuku Dergisi, Ekim 2006, sh. 40).

1970’li yıllara kadar İtalyan ve Fransız ceza hukukunun etkisinde kalmış olan Türk ceza hukuku doktrininde hata konusu henüz yeterli olarak irdelenmiş değildir. Hatırlatılmalıdır ki, yeni TCK’nın 30. maddesinin redaksiyonunda, özellikle Alman ceza hukuku doktrininde hataya ilişkin olarak yapılan tespitler ve varılan sonuçlar esas alınmıştır. Bu nedenle, söz konusu madde içeriği Türk ceza hukukçuları tarafından henüz tam olarak anlaşılmış değildir.

Yeni TCK’na ilişkin olarak TBMM’nde yaptığımız çalışmalarda 30. maddenin redaksiyonu sırasında karşılaştığımız izah zorlukları dolayısıyla, maddenin dördüncü fıkrasında şimdilik hatanın sadece kaçınılmaz olması haline özgü hüküm konulmasını tercih ettik. Dördüncü fıkrada, işlenen fiilin haksızlık oluşturduğu hususundaki hatanın kaçınılabilir olması haline ilişkin olarak hüküm bulunmamaktadır. Bu tercih tarafımızdan bilinçli olarak yapılmıştır. Ancak, bu durum, söz konusu fıkra metninde bir hata olduğu şeklinde değerlendirilmemelidir. Bu durum Türk doktrini ve özellikle uygulaması tarafından bir eksiklik olarak hissedildiği takdirde, söz konusu fıkra metnine “*Hatanın kaçınılabilir olması halinde, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.*” şeklinde bir cümle eklenmesiyle sorun halledilebilir (Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZAYDIN, sh. 253 vd.).

Ancak fıkranın mevcut metni karşısında, işlenen fiilin haksızlık oluşturduğu hususundaki hatanın kaçınılabilir olması halinde sorumluluk açısından nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususuna gerekçede açıklık getirilmiştir. Getirilen açıklığın, *Ünver*’in iddiasının aksine, 61. madde düzenlemesi ile çelişen bir yönü bulunmamaktadır.

⁹⁵⁹ İşlenen fiilin haksızlık oluşturduğu hususundaki hata ile ilgili tutarsız ve çelişkili açıklamalar için bkz. HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 263.

Bu hükmün uygulama alanıyla ilgili olarak mevzuatımızdan şu örnek verilebilir: 21.7.1983 t. ve 2863 s. “*Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu*”nun⁹⁶⁰ “*Haber verme zorunluluğu*” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasına göre;

“Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geç üç gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar.”

Yine söz konusu Kanunda, bu bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış, “*altı aydan üç yıla kadar hapis cezası*”nı gerektiren suç olarak tanımlanmıştır (m. 67, f.1)⁹⁶¹.

Kişi, kendisine miras yoluyla intikal eden örneğin bir tablonun tarihi bir değerinin olduğunun bilincinde olarak, bunu koruma hususunda gerekli bütün tedbirleri almış olabilir; ancak, bu tabloyla ilgili olarak bir bildirimde bulunma yükümlülüğünün olduğunu bilmediği için, Kültür Bakanlığı yetkililerine zamanında gerekli bildirimde bulunmamış olabilir.

Dikkat edilirse, bu durumda kişi, tarihi bir değerinin olduğunu bildiği tablo ile ilgili bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı hareket etmiştir. Kişi, elindeki tablonun tarihi değerinin olduğunu ve dolayısıyla bir kültür varlığı niteliğini taşıdığını bildiği halde; buna ilişkin olarak bildirim yükümlülüğünün olduğunu bilmeyebilir. İşte bu bilgisizlik, kişinin söz konusu ihmâlî davranışının bir haksızlık teşkil ettiği hususundaki hatayı ifade etmektedir⁹⁶².

Buna karşılık, kişinin, söz konusu bildirim yükümlülüğünün bilincinde olmakla birlikte, elindeki tablonun tarihi bir değeri olan kültür varlığı olduğunu bilme-

⁹⁶⁰ RG: 23 Temmuz 1983/18113.

⁹⁶¹ Söz konusu maddede 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle (m. 410) (RG: 8 Şubat 2008/26781), Kanunun 4. maddesindeki kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili bildirim yükümlülüğüne “*mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi*” hakkında ceza sorumluluğu öngörülmüştür. Bu itibarla, söz konusu suçun oluşabilmesi için, **failin kültür varlığının bu özelliğini bilmesi gerekmektedir**. Yani bu suç, ancak **doğrudan kastla** işlenebilir. Nitekim, söz konusu Kanunun bildirim yükümlülüğünü ihdas eden 4. maddesinde “*taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulan... (ya da) malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilen... veya yeni haberdar olan malik ve zilyet*” ibaresi kullanılmıştır. Keza, söz konusu suçtan dolayı ceza sorumluluğu için, kişinin bildirim yükümlülüğünü yerine getirme bakımından **mazeretinin olmaması** gerekmektedir. Burada mazeretin varlığı **kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep** olarak anlaşılmalıdır.

⁹⁶² Bu örnek, TBMM Adalet Komisyonunun 30.6.2004 tarihli toplantısında söz konusu maddeye ilişkin olarak yapılan tartışmalar sırasında tarafımızdan verilmiştir. Bu örnekle ilgili açıklama için ayrıca bkz. MERAN, Necati: *Türk Ceza Kanununda Yasak Hatası*, in: Terazî Aylık Hukuk Dergisi, yıl 4., sayı 32, Nisan 2009, sh. 65 vd.

mesi halinde, 2863 s. Kanunun 67. maddesinde tanımlanan ve ancak ihmalî davranışla işlenebilen bu suça ilişkin kastının varlığından söz edilemez⁹⁶³.

Ancak, kişi, icra ettiği meslek ve sanat itibarıyla tarihi eserler ve bu hususla ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olan birisi ise; bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, ceza hukuku bakımından sorumlu olacaktır^{964,965,966}.

⁹⁶³ Bu itibarla, Yargıtay'ın bu konuda verdiği kararlar, ceza hukukunun vazgeçilmez kurallarından biri olan kusura dayalı sorumluluk ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Yargıtay'a göre; söz konusu bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidilebilmesi için, suçun konusunu oluşturan şeyin bir tarihi eser olduğunu failin bilip bilmediğinin değil; bilirkşi marifetiyle suç konusu şeyin tarihi eser niteliğinde olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. 11. CD, 5.11.1998, 7427/6871 (Kanadoğlu, Sabih: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku, 2. bası, Ankara, 2003, sh. 397); 11. CD, 14.5.1997, 1918/2297 (Kanadoğlu, sh. 399); 11. CD, 12.11.1996, 2180/2182 (Kanadoğlu, sh. 399); 11. CD, 13.4.2000, 1192/1353 (Kanadoğlu, sh. 393). Ayrıca bkz. Gündel, Ahmet: Açıklamalı ve İçtihatlı Eski Eserler Hukuku, Ankara, Mayıs 1996, sh. 257 vd.

⁹⁶⁴ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 31.3.2015 tarihli ve E. 2013/12-770, K. 2015/84 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; İzmir Adnan Menderes Havalimanından 14.02.2008 tarihinde uçakla İstanbul'a gidecek olan yolculardan Sıdika'nın çantasının giden yolcu x-ray cihazından geçirildiği sırada kontrol edilmesi sonucunda, çantada bulunan halen tedavül kabiliyeti olmayan çok sayıda madeni paraya elkonulur.

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde görevlendirilen bilirkşilerce hazırlanan raporlarda, bu madeni paralardan önemli bir kısmının, 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre **korunması gereken kültür varlığı** olduğu tespit ve değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Sanık savunmasında şu açıklamalarda bulunmuştur: “*Babam 2004 yılında vefat etmiştir. 11.02.2008 günü İzmir'de açılacak bir sergi için İstanbul'dan İzmir'e gittim. Annem İzmir'de oturuyor. Annem, babamın koleksiyon yapmak için biriktiği madeni paraları babamdan kalma hatıra olduğundan bana verdi. Ben de bunları babamın hatırası olduğu için, İstanbul'daki evime götürmek üzere aldım.*”

Tanık sıfatıyla dinlenen sanığın annesi ise ifadesinde; “*Sanık benim kızımdır. Babası ile 1956 yılında evlendim. Kocam bu sikkeleri 50 sene kadar önce amatör olarak aldı. Daha sonra koleksiyona devam etmedi. 50 yıldır İzmir'deki evimizde duruyordu. Kocam 2004 yılında vefat etti. Olay tarihinden önce İstanbul'da oturan kızım Sıdika İzmir'e beni ziyarete gelmişti. Artık yaşlandığım için ziynetlerimi çocuklarıma dağıtmıştım. Son olarak da kıymetini ve ne olduğunu bilmediğim suça konu sikkeleri kızıma verdim. Bu sikkeleri daha kızım doğmadan önce babası almıştı. Sikkeler bez bir torba içinde duruyordu.*” açıklamasında bulunmuştur.

Davanın görüldüğü İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi 17.12.2008 tarihli ve 201-734 sayılı kararı ile sanığın “**suç kastı olmadığından**” bahisle beraatine karar vermiştir.

Yargıtay 12.CD, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda verdiği 20.06.2012 tarihli ve 9486-15482 sayılı Kararla “*sanığın eylemi 2863 sayılı Yasanın 70. maddesine temas eden suçu oluşturduğu halde, suç kastı bulunmadığı şeklindeki ... gerekçe ile beraatine karar verilmesi*”ni hukuka aykırı bulmuş ve söz konusu beraat kararını bozmuştur.

İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 15.11.2012 tarihli ve 866-1222 sayılı Kararı ile önceki kararında direnmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise, aşağıdaki gerekçeyle, İlk Derece Mahkemesinin direnme hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

2863 sayılı Kanuna göre; “*Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat*

varlıkları Devlet malı niteliğindedir.” (m. 5, f. 1). Bu itibarla, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları “Devlet malı” niteliğindedir.

Keza, “Devlet malı niteliğini taşıyan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının Devlet elinde ve müzelerde bulundurulması ve bunların korunup değerlendirilmeleri Devlete aittir. Bu gibi varlıklardan gerçek ve tüzelkişilerin ellerinde bulunanlar, değeri ödenerek Bakanlık tarafından satın alınabilir.” (2863 s. Kanun, m. 24, f. 1).

Söz konusu Kanunun 70. maddesinde ise bu bağlamda bir suç tanımına yer verilmiştir:

“Bu Kanunun 24 üncü maddesine aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.” Buna göre, 2863 sayılı Kanunun 24. maddesine aykırı şekilde, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulundurma eylemi suç oluşturmaktadır.

Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarını, **bu niteliğini bilerek** kanunda öngörülen usul ve esaslara aykırı şekilde elde bulundurma halinde suç oluşur.

CGK kararına göre, heykeltraş olan sanığın branşı ve eğitim durumu gözetildiğinde, suçun konusunu oluşturan sikkelerin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınır **kültür varlığı olduğunu bildiğinin kabulü** gerekmektedir.

Kanaatimizce burada sorun söz konusu sikkelerin kültür varlığı olduğunun bilinip bilinmemesi sorunu değildir. CGK kararında da belirtildiği gibi, fail, bu sikkelerin kültür varlığı olduğunu bilmektedir.

Burada iki sorun bulunmaktadır. Birinci sorun, işlendiği kabul edilen suçun doğru belirlenip belirlenmediği sorunudur. Esasında bu olayın, 2863 sayılı Kanunun 4. maddesiyle ihdas edilen yükümlülük ve bu yükümlülüğün ihlalini suç olarak tanımlayan 67. maddesi bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekirdi. Oysa Yargıtay, söz konusu olayı ilgisiz hükümler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutmuştur.

İkinci sorun ise, söz konusu suç bakımından failin haksızlık bilincinin bulunup bulunmaması sorunudur. Söz konusu olayda fail, işlediği fiilin bir haksızlık oluşturduğu hususunda hataya düşmüştür. Bu hatasının, işlediği suç bakımından sadece kusurluluğu üzerinde etkisi vardır; ancak, kast üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak, gördüğü öğrenim ve icra ettiği meslek gibi faktörler göz önünde bulundurularak, failin bu hatasının kaçınılmaz olup olmadığı tartışılabilir.

⁹⁶⁵ **Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 31.1.2012** tarihli ve E. 2010/142, K. 2012/20 sayılı Kararına konu teşkil eden olay şu şekilde cereyan eder:

Birbirlerini karşılıklı olarak seven **8.10.1994** doğumlu olan Gülay ile **1.1.1986** doğumlu olan Hasan, anne ve babalarının karşılıklı rıza ve muvafakatiyle, **19.10.2008** tarihinde yapılan bir düğün töreni ile evlendirilirler ve bu tarihten itibaren karı koca gibi birlikte yaşamaya devam ederler. Bu birliktelikten bir çocukları da dünyaya gelen Gülay ve Hasan, bilahare Gülay’ın 16 yaşını tamamlaması üzerine resmen nikâhlanırlar.

Bu olayla ilgili olarak 19.10.2008 tarihi itibarıyla Gülay’ın henüz 14 yaşını tamamlamamış olması sebebiyle Hasan ile Hasan’ın anne ve babası ve Gülay’ın anne ve babası hakkında henüz 15 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cinsel istismar suçunu iştirak halinde işlediklerinden bahisle açılan kamu davasında Mahkeme aşağıdaki gerekçeyle sanıklar hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı vermiştir:

“Sanıkların, savunmalarına ve dosya kapsamına göre, işledikleri fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri kabul edilmelidir.

...

Failin, işlediği fiilin genel olarak hukuk düzenince haksız olarak kabul edildiği konusunda hataya düşmesi, başka deyişle, fiilin hukuka aykırı olmadığı zannı ile hareket etmesi ve bu hatasının kaçınılmaz nitelikte bulunması durumunda, hatasından yararlandırılması gerekir.

Hatanın kaçınılmaz olmadığının takdirinde, failin suçu işlerken içerisinde bulunduğu şartlar, bilgi düzeyi, eğitimi, sosyal ve kültürel koşulları göz önünde bulundurulur. Böyle bir hata içe-

risinde olan kişinin durumu, her somut olayda hakim tarafından değerlendirilecektir. Belirtilen ölçütler göz önüne alındığında kişi açısından kaçınılmaz bir durum varsa kişinin fiilinden dolayı ceza sorumluluğu olmayacaktır.

...

Sanıklar Nevşehir İli Acıgöl İlçesi İnallı Kasabasında ikamet etmektedirler. Sanıklar ilkökul ve ortaokul mezunu olup, meslekleri işçilik, çiftçilik, hurdacılık ve ev hanımlığıdır. Bulundukları sosyal ve kültürel çevrede çocuklar genel olarak küçük yaşta evlendirilmektedir ve bu, hukuka aykırı bir durum veya olumsuz bir davranış olarak algılanmamaktadır. Sanıklar(dan) İsmail, Ceylan ve Hacer, anne-babalarının ve kendilerinin de küçük yaşta evlendiklerini ifade etmektedirler. Sanıkların amaçları çocuklarını evlendirerek mutlu bir birliktelik sağlanmasına yardımcı olmaktır. Olayda, cinsel istismara yönelik bir emare bulunmamaktadır. Evlenme töreni yöre âdetlerine göre herkese açık şekilde yapılmıştır. Bu husus, dosya içerisinde yer alan ve törenin yöre âdetlerine göre yapıldığını gösteren düğün davetiyesinden anlaşılmaktadır. Düğün davetiyesinde, 'Bayrak', 'Kına' ve 'Gelin Alma' günleri ayrı ayrı belirtilmiştir. Nitekim, daha sonra sanık Hasan ve mağdure arasında resmi nikah kıyılmış, çocukları olmuş ve mutlu birliktelikleri devam etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ve belirtilen ölçütlere göre sanıkların kişisel durumlarının değerlendirilmesi sonucunda, sanıkların içinde bulundukları sosyal ve kültürel çevre ile eğitim ve bilgi düzeylerine göre, işledikleri fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz ve kusurluluklarını ortadan kaldıran bir hataya düştükleri kanaatine varılmıştır. Zira, eylemin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşülmemiş olsaydı yöre âdetlerine göre herkese açık şekilde evlenme töreni yapılmaz ve herkese ilan eder şekilde düğün davetiyesi dağıtılmazdı. Düğün davetiyesinin basılması ve herkese açık şekilde düğün yapılması, yörede küçük yaşta çocuk evlendirmenin hukuka aykırı bir davranış olmadığı hususunda yaygın bir kanı olduğuna işaret etmektedir. Bu husus da, sanıkların, işledikleri fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düştüklerini göstermektedir.

Açıklanan nedenlerle, **sanıkların** içinde bulundukları sosyal ve kültürel çevre ile eğitim ve bilgi düzeyleri göz önüne alınarak, **işledikleri fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz ve kusurluluklarını ortadan kaldıran bir hataya düştükleri kanaatine** varıldığından, sanıklara **ceza verilmesine yer olmadığına** ilişkin ... karar oluşturulmuştur."

Söz konusu kararı, gerekçesi ve sonucu itibarıyla **doğru** bulduğumuzu ifade etmek isteriz.

Ancak, Yargıtay, bu hususa özgü olarak karar vermekten imtina etmektedir. Her ne kadar bazı kararlarında konu ele alınmış ise de, bütün bu kararlarda **suçun maddi unsurlarında hata** ile ilgili olarak soruna çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Bkz. Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun **5.11.2013** tarihli ve K. 2013/432, K. 2013/440 sayılı; **12.11.2013** tarihli ve K. 2013/445 sayılı; **26.11.2013** tarihli ve K. 2013/514, 2013/515, 2013/516, 2013/517, 2013/518 sayılı; **3.12.2013** tarihli ve K. 581 sayılı; **24.12.2013** tarihli ve K. 2013/625, K. 2013/626 sayılı, **14.1.2014** tarihli ve K. 2014/8, 2014/9 sayılı; **21.1.2014** tarihli ve K. 2014/13, K. 2014/14, K. 2014/15 sayılı; **4.2.2014** tarihli ve K. 2014/33, K. 2014/34 sayılı; **11.2.2014** tarihli ve K. 2014/67, K. 2014/68 sayılı; **18.2.2014** tarihli ve K. 2014/76 sayılı; **25.2.2014** tarihli ve K. 2014/95 sayılı Kararları.

⁹⁶⁶ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **15.9.2015** tarihli ve E. 2013/14-749, K. 2015/277 sayılı kararına konu teşkil eden olayda 22.6.1993 doğumlu Gözde, aynı köyde doğmuş ve kendisinden birkaç yaş büyük olan Mehmet ile arkadaşlıklar zamanla duygusal arkadaşlığa dönüşür, 2008 yılında evlenmek amacıyla birlikte kaçarlara ve aralarında müteaddit defa cinsel birleşme gerçekleşir.

Ceza Genel Kurulu, çocuk yaşta olan (üçüncü grup yaş küçüğü) Mehmet'in, 14 yaşından gün alan ve fakat bu yaşı henüz tamamlamayan Gözde ile cinsel ilişkiye girmesi fiili bağlamında, "sanığın mağdureyi uzun süredir tanınması ve ailesinin yaşı küçük olduğu için evlenmelerine izin vermediğini bilmesi karşısında, mağdurenin onbeş yaşından küçük olduğunu bilmemesi

hayatın olağan akışına aykırı olup somut olayda TCK'nın 30. maddesinde düzenlenen hata halinin uygulanma şartları mevcut değildir"

gerekçesiyle, Esas Mahkemesinin Mehmet hakkında verdiği çocuğun cinsel istismarı suçundan (TCK, m. 103) mahkumiyet hükmünün onanmasına karar vermiştir.

Dikkat edilmelidir ki, dosyada Gözde ile Mehmet'in bilahare **10.7.2011** tarihinde **evlenmiş** olduklarına ve bu birlikteliklerinden, birincisi evlilik öncesinde 21.7.2010 tarihinde, ikincisi ise evlilik birliği içinde 20.5.2014 tarihinde dünyaya gelmiş **iki çocuk** sahibi olduklarına dair bilgi mevcuttur. Başka bir ifadeyle Ceza Genel Kurulu, Mehmet hakkında hükmolunan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasının onanması yönünde karar verirken bu bilgilere vakıftır.

Karara konu teşkil eden olayda, mercilerce Mehmet tarafından suçun maddi unsurlarında, yani Gözde'nin yaşı ile ilgili olarak, hataya düşülüp düşülmediği tartışma konusu yapılmıştır. Bu tartışmanın arkasındaki düşünceye göre, şayet Mehmet onbeş yaşını tamamlamış olduğunu zannederek Gözde ile cinsel birliktelik gerçekleştirmiş ise, cinsel istismar suçuna ilişkin olarak kastı bulunmamaktadır. Bu durumda Mehmet'in fiilini TCK, m. 104, f. 1 kapsamında değerlendirmek gerekecektir. Somut olayda Gözde'nin şikayeti olmadığı için Mehmet'in cezalandırılması cihetine gidilemeyecektir.

Burada sorun, bir kast sorunu değildir. Bu tür olaylarda fail, cinsel birliktelik gerçekleştirdiği mağdurenin henüz onbeş yaşını tamamlamadığını bilebilir. Ancak, fail, mağdurenin yaşının küçük olduğunu bilmesine rağmen, fiziki yapısı itibarıyla cinsel bütünlüğü üzerinde tasarrufta bulunma olgunluğuna eriştiğini düşünerek hareket etmiş olabilir. Somut olayda fail mağdureyle olan cinsel birlikteliğini içinde yaşadığı toplum telakkileri itibarıyla "meşruiyet" zeminine oturtma çabası içindedir. Nitekim fail, mağdurenin Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 16 yaşını tamamlaması üzerine mahkemeye başvurarak yargı kararıyla reşit kılınmasını sağlamış ve bilahare de mağdure ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre akdedilen nikâhla evlenmiştir.

Bu durum karşısında, aralarında sadece birkaç yıl yaş farkı bulunan failin, mağdureyle cinsel birlikteliği bağlamında gerçekleştirdiği fiilin haksızlık oluşturduğunun bilincinde olmadığını ve bu konudaki hatasının kaçınılmaz olduğunu kabul etmek gerekir.

Fail ile mağdure arasında evlilik birliğinin gerçekleşmiş olmasına ve bu cinsel birliktelikten dünyaya gelmiş iki çocuğun bulunmasına rağmen, artık reşit kılınmış eş bakımından koca, dünyaya gelmiş iki çocuk bakımından baba olmanın sorumluluğunu taşıyan kişinin mahkum olduğu **5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasının** kesinleşmesini sağlayan, Ceza Genel Kurulu'nun oy çokluğuyla verdiği söz konusu karar, hukukla izah edilemez.

Türk yargısı bu çerçevede ortaya çıkan sorunları, failin kastı bağlamında tartışarak bir sonuca bağlamaya çalışırken, TCK, m. 30, f. 4'de düzenlenen haksızlık hatası bağlamında değerlendirmeye yanaşmamaktadır. Söz konusu hukuki sorunun çözümüyle ilgili olarak Türk yargısının bu çekingenliği, egemen siyaseti bu sorunun, hukuki olmayan başka uygulamalara sebebiyet vermesi pahasına da olsa, yasama faaliyetiyle çözümlenmesi arayışlarına sevk etmiştir ve etmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **2.6.2015** tarihli ve E. 2014/14-47, K. 2015/178 sayılı Kararına konu teşkil eden benzer olayda; 1.6.1992 günü hastane doğumlu olarak dünyaya gelen ve lise birinci sınıf öğrencisi olan ondört yaşını tamamlamamış olan Neşe ile kendisinden dokuz yaş büyük Erdal bir buçuk yıllık arkadaşlığın ardından birçok kez cinsel ilişkiye girerler; Neşe'nin hamile kalması üzerine evlenmek isterler; ancak Neşe'nin yaşının küçük olması nedeniyle resmî nikah işlemlerini yapamazlar; ardından dini nikâhla evlenip Erdal'ın anne ve babasının evinde birlikte yaşamaya başlarlar.

Neşe 16.5.2007 tarihinde bir çocuk dünyaya getirir ve çocuk Erdal'ın nüfusuna kaydedilir. Bilahare Neşe ve Erdal, 10.2.2009 tarihinde resmi nikâhla evlenirler.

Bu olayda Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi Erdal hakkında;

a) Çocuğun cinsel istismarı suçunun nitelikli halini müteselsilen işlediğini kabul ederek, TCK, m. 103, f. 2; m. 43, f. 1 ve m. 62 hükümleri uyarınca **sekiz yıl dört ay hapis cezasına**,

III. Hata Hükümlerinin Kabahatler Hakkında Uygulanması

5326 s. Kabahatler Kanununun “Hata” başlıklı 10. maddesine göre, “*Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler bakımından uygulanır.*”

b) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediğini kabul ederek, TCK, 109, f. 1, 3, 5 ve m. 62 hükümleri uyarınca, ayrıca **iki yıl altı ay hapis cezasına**, hükmetmiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise, Erdal’ın Neşe’nin yaşına ilişkin olarak hataya düşüp düşmediğinin araştırılmadığı gerekçesiyle, bu mahkumiyet hükmünü bozmuştur.

Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bozma kararına itiraz etmiştir. Başsavcılığın görüşüne göre, Neşe’nin yaşına ilişkin olarak Erdal’ın “kaçınılmaz” bir hatası söz konusu değildir.

Ceza Genel Kurulu, bu olayda TCK, m. 30’da düzenlenen hata hükümlerinin uygulanma şartlarının mevcut olmadığı ve failin, çocuğun cinsel istismarı (TCK, m. 103) ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK, m. 109) suçlarından cezalandırılması yönünde kurulan mahkumiyet hükmünün hukuka uygun olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.

Birinci olaydan farklı olarak, bu olayda failin, mağdure ile arasındaki yaş farkının fazlalığı karşısında, gerçekleştirdiği fiilin haksızlık oluşturduğu hususundaki hatasının **kaçınılabılır** olduğu değerlendirilmesinde bulunulmalıdır.

§20. Suça Teşebbüs

I. Teşebbüsün Hukuki Niteliği

Suç, bir *süreç* içinde işlenmekte olup, buna **suç yolu** (*iter criminis*) denmektedir. Bu süreçte önce hazırlık hareketleri, daha sonra icra hareketleri gerçekleştirilmektedir. Kanuni tarifte ayrıca bir unsur olarak neticeye yer verilmişse, fiil icra edildikten sonra bu netice de gerçekleşmiş olmalıdır ki, söz konusu süreç tamamlanmış olsun. Meselâ, A, B'yi öldürmeyi düşünür; A bu düşüncesini hayata geçirmek için önce bir plan yapar; fiilin icrası için gerekli gördüğü silah ve mermiyi temin eder. Daha sonra B'nin geçeceği yol üzerinde pusu kurar ve nihayet, B yoldan geçerken silahını ateşleyerek onu öldürür.

Ceza hukukunun müdahalesi için, kişinin suç işleme bilinç ve iradesiyle herhangi bir biçimde faal hale geçmesi yeterli olmayıp, bu halin belirli bir nitelik ve niceliğe ulaşması gerekir. Meselâ, B'yi öldürmeye karar vermiş olan A, bu amaçla, bir bıçak veya zehir temin etmiş olabilir. Fiil bu aşamada kalmış ise, A'nın kasten öldürme suçundan dolayı cezalandırılması söz konusu olmayacaktır. Çünkü bir suçun işlenmesine yönelik **hazırlık hareketleri**, o suçun icrası cümlesinden olarak cezalandırılabilir hareketler değildir⁹⁶⁷. Meğer ki bu hareketler bizatihi cezalandırılabilir nitelikte hareketler olsun ve müstakil bir suç oluştursun.

Suçun kanunî tarifinde belirlenmiş olan fiilin icrasına başlanmış olmakla birlikte, bu fiile ilişkin **icra hareketleri** henüz tamamlanmamış olabilir. Keza, fiil icra edilmiş olmakla birlikte; suçun kanunî tarifinde ayrıca bir unsur olarak belirlenmiş olan netice henüz gerçekleşmemiş olabilir. Bu durumlarda suçun kanunî tarifindeki bütün unsurların gerçekleşmiş olduğunu söyleyemeyiz. Ancak, fail bu ihtimallerde *suç yoluna* (*iter criminis*)⁹⁶⁸ girmiş ve gerçekleştirdiği hareketler bizatihi bir haksızlık mahiyeti kazanmıştır. Bu nedenle, suç yoluna girmiş olan bu failin, suçun kanunî tarifindeki bütün maddi unsurlar gerçekleşmediği gerekçesiyle cezalandırılmasından sarfınazar edilemez. Ancak, ifade etmek gerekir ki; failin bu sebeple cezalandırılabilmesi için, suçun kanunî tarifinin yanı sıra, fiilin icrasının tamamlanamaması veya kanunî tariftaki neticenin gerçekleşmemesi halinde de cezalandırmaya imkân tanıyan bir kanunî düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu nedendir ki; ceza kanunlarında suçun teşebbüs derecesinde kalması halinde de failin cezalandırılmasına imkân sağlayan hükümlere yer verilmiştir. Bu itibarla, suçun teşebbüs derecesinde kalması halinde de cezalandırılmasına imkân sağlayan bu hükümler **cezalandırılabilirliği genişleten hükümler** niteliğindedir⁹⁶⁹.

⁹⁶⁷ ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 454, 776 vd..

⁹⁶⁸ SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 261.

⁹⁶⁹ "Strafausdehnungsgrund". SOYASLAN, Teşebbüs Suçu, sh. 22, 38, 51, 52, 55; aynı yazar, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 337; DÖNMEZER/ERMAN I, no. 549, 551.

Teşebbüse ilişkin bu hükümler, somut bir olayda tek başına uygulanamazlar. Bunlar, ancak muayyen bir suçun tanımlandığı kanun hükmüyle birlikte uygulama kabiliyetine sahiptirler. Bu nedenle, suça teşebbüs durumunda bağımsız bir “teşebbüs suçu”ndan söz edilemez. Failin işlediği fiil kanunda hangi suçun icraî hareketleri kapsamında mütalâa edilmekte ise, teşebbüs durumunda yine bu suçun cezası dikkate alınmak gerekir. Bu itibarla, teşebbüs halini müstakil bir suç olarak telâkki eden görüşlerin isabetli olmadığı düşüncesindeyiz.

Teşebbüse ilişkin genel hükümler, bir suçun tamamlanamadığı durumlarda, ancak bu suçun kanuni tarifiyle birlikte, bu hükmün yanında, bununla bağlantılı olarak uygulama kabiliyetini haizdirler. Bu nedenle, teşebbüs hükümleri, **yardımcı norm** karakteri taşımaktadır⁹⁷⁰.

Esasen haksızlık teşkil eden bazı insan davranışlarının ceza kanunlarında suç olarak tanımlanmasıyla güdülen amaç, belirli hukuki değerlerin daha etkin bir şekilde korunmasıdır. Teşebbüse ilişkin hükümler, bu suç tanımlarıyla korunan hukuki değerlerin koruma alanını genişletmektedir. Suçun kanuni tarifindeki fiilin icrasının tamamlanmamasına, tamamlanmış olmakla beraber neticenin gerçekleşmemiş olmasına rağmen, fail cezalandırılmaktadır. Bu nedenledir ki, teşebbüse ilişkin hükümler cezalandırılabilirliğin alanını genişletmektedir.

Bir suçun kanuni tarifinde korunan hukuki değer ihlâli, bu tarifte yer alan fiilin icrasına başlamakla gerçekleşmektedir. Ancak, bu fiilin icrasında katedilen mesafeye göre, o suçun konusu tehlikeye veya zarara maruz bırakılmaktadır. Bu tehlikeye veya zarara maruz bırakış ile fail ilgili hukuki değeri tanımadığını, onun geçerliliğine karşı çıktığını göstermektedir⁹⁷¹. Teşebbüs durumunda, ilgili suç tanımıyla korunan hukuki değer ihlâl edilmiş olmaktadır. Ancak, suç yolunda katedilen mesafeye göre suçun konusu bir tehlikeye ve hatta bir zarara maruz bırakılmış olmaktadır. Bu itibarla, bir suçun işlenmesine teşebbüsten dolayı failin cezalandırılabilmesi için, gerçekleştirdiği hareketlerin o suça ilişkin konuyu en azından bir tehlikeye maruz bırakması gerekir⁹⁷². Cezalandırılabilirlik açısından bu tehlikenin ölçütü, failin gerçekleştirdiği davranışların en azından hazırlık hareketi olmaktan çıkıp, icra hareketi niteliğini kazanmasıdır.

Tamamlanmış olan suç, teşebbüs aşamasında kalmış olan suça nazaran; neticesi gerçekleşmiş olan fiil, icrası tamamlanmış olmakla birlikte, henüz neticesi gerçekleşmemiş olan fiile nazaran; icrası tamamlanmış olan fiil, icrasına başlanmış olmakla birlikte, henüz tamamlanmamış olan fiile nazaran; keza, bir suçun icra

⁹⁷⁰ JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch(5), sh. 515; İÇEL, Suçların İçtimai, sh.213/214.

⁹⁷¹ GALLAS, Wilhelm: *Zur Struktur des strafrechtlichen Unrechtsbegriff*, in. Festschrift für Paul Bockelmann, München, 1979, sh. 159; SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh.148/149.

⁹⁷² WOLTER, Jürgen: *Objektive und personale Zurechnung von Verhalten, Gefahr und Verletzung in einem funktionalen Straftatsystem*, Berlin, 1981, sh. 29, 50.

hareketleri, hazırlık hareketlerine nazaran daha fazla haksızlık içeriğine sahiptir. Taraftar olduğumuz “**fiil ceza hukuku**” düşüncesine göre, ne kadar tehlikeli bir kişiliğe sahip olursa olsun, bir insan ancak işlediği fiil sebebiyle cezalandırılabilir. İşlediği fiil dolayısıyla hakkında hükmedilecek cezanın türünün ve miktarının belirlenmesinde kişinin tehlikelilik durumu dikkate alınır. Ancak, sadece kişilik olarak arz ettiği tehlikelilik dolayısıyla kişi hakkında cezaya hükmedilemez. Bu itibarla, muayyen bur suçu işlemeye karar vermiş olmakla birlikte, bu suçun icrasına henüz başlamamış ise, hazırlık hareketlerinde bulunmuş olsa bile, bu hareketler başka müstakil bir suç oluşturmadığı sürece, kişi cezalandırılmaz. Başka müstakil bir suç oluşturmayan bu hazırlık hareketleri, kişinin tehlikeliliğini ortaya çıkarmış olabilir ve hatta, kişi henüz bir hazırlık hareketinde bulunmadan da bir suç işleme yönündeki kararını izhar etmiş, açıklamış olabilir. Bu durumlarda, henüz suç oluşturan bir fiilin icrasına başlanmadığı için ceza hukuku devreye girmez ve sorun, sadece **önleyici kolluk** faaliyeti çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmelidir. Başka bir ifadeyle, bu gibi durumlarda, kişilik olarak arz ettiği tehlikelilik dolayısıyla kişi hakkında **önleyici kolluk tedbirleri** uygulanabilir ise de, ceza hukuku yaptırımları uygulanamaz.

Suçta teşebbüs dolayısıyla kişinin cezalandırılabilmesi için aranan koşullar aşağıda açıklanmıştır:

II. Kasten İşlenen Suçun Varlığı

Teşebbüsten söz edebilmek için, kişinin belli bir suçu işlemek yönünde kastla hareket etmesi gerekir. Suçun özel bir görünüş şekli olan teşebbüse ilişkin TCK hükümleri ancak kasten işlenen suçlar bakımından uygulanabilir. Başka bir deyişle, taksirle işlenen suçlarla bağlantılı olarak teşebbüsten söz edilemez. Örneğin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranış sonucunda bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet verilmesi halinde taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu işlenmiş olmaktadır. Dikkat ve özen yükümlülüğüne salt aykırılık bir haksızlık oluşturmakla birlikte, çoğu zaman müstakil bir suç oluşturmamaktadır. Bu itibarla, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışın gerçekleşmesine rağmen bu nedenle herhangi bir kişi ölmüş veya yaralanmış olmayabilir. Bu gibi durumlarda taksirle ölüme veya yaralamaya sebebiyet verme suçlarına teşebbüsten söz edilemez.

Belli bir suçun işlenmesine teşebbüs edilmesi durumunda, failin kastı kapsam ve içerik açısından tamamlanmış suçtan bir farklılık göstermez⁹⁷³. Bu nedenle,

⁹⁷³ “... suçta teşebbüsle ilgili değerlendirme yapılabilmesi failin hangi suçu işlemeyi kastettiğinin belirlenmesini gerektirir. Buna sübjektif unsur denir. Failin gerçekleştirdiği davranış ile bir suçu işlemeye teşebbüs edip etmediğini, eğer etmişse hangi suça teşebbüs ettiğini saptayabilmek için öncelikle kastın varlığının belirlenmesi gerekir. Başka bir deyişle, tıpkı tamamlanmış suçta olduğu gibi, teşebbüs aşamasında kalan suçta da, işlenmek istenen suç tipindeki bütün unsurlar failce bilinmelidir.

“suç kararı” adı altında ayrı bir teşebbüs kastından söz edilemez⁹⁷⁴. Belli bir suç işlemeye teşebbüs eden failin kastı, söz konusu suçun tamamlanmasına yöneliktir. Nitekim, Yargıtay da aynı gerçeğe işaret etmiştir:

«Teşebbüste aranan kast, icrasına başlamış cürmü teşebbüs derecesinde bırakma kastı olmayıp söz konusu suçu tamamlamaya yönelmiş kasttır. Bu itibarla teşebbüs kastından söz edilemez. Tamamlanmış suç için ayrı, teşebbüs derecesinde kalmış suç için ayrı kast düşünülemez.»⁹⁷⁵.

Teşebbüs açısından kastın belirlenmesinde, her somut olayın meydana geliş şartları göz önünde tutulacaktır⁹⁷⁶.

Olası (muhtemel) kastın varlığı durumunda suça teşebbüsün mümkün olup olmadığı tartışma konusu olmuştur.

Türk hukukunda bir görüş, olası (muhtemel, gayrimuayyen) kast netice ile belirlenir düşüncesinden hareketle, gerçekleşmesi muhtemel olan neticenin ancak gerçekleşmesi halinde failin bu neticeden dolayı sorumlu tutulabileceği fikrindedir⁹⁷⁷. Buna karşılık, Alman doktrininden esinlenen diğer bir görüşe göre, olası kastla işlenen suç açısından da teşebbüs hükümleri uygulanabilir⁹⁷⁸. Zira, kanun teşebbüs açısından failin kasten hareket etmesini aramaktadır. Fakat bu kastın doğrudan veya muhtemel, muayyen veya gayrimuayyen kast olması arasında bir ayırım yapmamıştır⁹⁷⁹.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **5.2.2019** tarihli ve E. 2018/310, K. 2019/62 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; S, av tüfeğiyle R’yi hedef alarak ve **öldürme kastıyla** bir el ateş eder. Ancak, R kendini hemen yana atması sebebiyle, yaralanmaktan kurtulur. Tüfek namlusundan çıkan çok sayıda saçma tanesi R’nin hemen arkasında bulunan kızı P’ye isabet eder ve P yaralanır.

... (B)ir eylemin kasten öldürmeye teşebbüs mü, yoksa kasten yaralama mı sayılacağına belirlenmesi sırasında; **suç nedeni, kullanılan aletin cinsi, kullanılış şekli, isabet alınan bölge, darbe adedi ve şiddeti, failin suçtan önceki ve sonraki davranışları, aradaki husumet, hedef seçme olanağının bulunup bulunmadığı, mağdurdaki yaraların yerleri ve nitelikleri, failin fiiline kendiliğinden mi, yoksa engel bir nedenden dolayı mı son verdiği gibi ölçütlere** başvurulmaktadır.”: CGK, **13.10.2009**, E. 2009/1-141, K. 2009/229. Ayrıca bkz. CGK, **26.2.2013**, E. 2012/1-1558, K. 2013/72.

⁹⁷⁴ Erem, teşebbüs açısından kast kavramından ayrı bir “suç kararı”ndan söz etmektedir: EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 294/295.

⁹⁷⁵ CGK, 4.6.1990, 5-101/156, (YKD, Kasım 1990, sh. 1700).

⁹⁷⁶ Ayrıntılı bilgi için bkz. İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 317 vd.; DÖNMEZER, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, no. 18.

⁹⁷⁷ DÖNMEZER/ERMAN II, no.930; SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 334, 335; ÖZTÜRK, Ceza Hukuku(3), sh. 130/131, 208/209.

⁹⁷⁸ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 305, 435; SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 162 vd.

⁹⁷⁹ BAUMANN/WEBER/MITSCH, sh. 545; JESCHECK (4), sh. 464; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 28.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu olayda, S'nin R'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürme suçunu, buna karşılık P'ye karşı ise olası kastla yaralama suçunu işlediğini kabul etmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu kabulden hareketle, söz konusu olayda iki **farklı suçun** oluştuğu ve farklı neviden fikri içtima hükümlerinin (TCK, m. 44) gereği olarak bu suçlardan sadece kasten öldürme suçuna teşebbüsten dolayı cezaya hükmetmek gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

Bu içtihadın temelindeki sorun, olası kastla işlenen suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanabilip uygulanamayacağı sorunudur.

Kitabımızın 15 ve önceki basılarında olası kastla işlenen suçlarda sorumluluğun neticeyle belirlenmesi gerektiği düşüncesi benimsenmişti (15. bası, sh. 498). Özellikle suçların içtimai bakımından ortaya çıkardığı içtihat farklılıkları⁹⁸⁰ dik-

⁹⁸⁰ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **18.10.2018** tarihli ve E. 2015/158, K. 2018/444 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; T, av tüfeğini üç dört metre mesafede bulunan K'ye doğrultarak bir el ateş eder. Tüfek namlusundan çıkan çok sayıda saçma tanesi K'ye isabet eder ve K, hayatı tehlike geçirecek şekilde yaralanır. Ancak bu saçma tanelerinden bir kısmı K'nin hemen yanında bulunan O'nun bacağına isabet eder ve O, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanır.

İlk derece mahkemesi, bu olayda T'nin fiilinin mağdur K'yi kasten öldürme suçuna teşebbüs ve O'yu kasten (olası kastla) yaralama suçunu oluşturduğunu kabul ederek, T hakkında her iki suçtan dolayı gerçek içtima hükümlerine göre hapis cezasına hükmetmiştir.

Söz konusu hükmü temyizden inceleyen Yargıtay 1.CD, oyçokluğu ile verdiği kararında, T'nin "eyleminin hukuki anlamda tek bir fiil olduğu, bu fiille birden fazla farklı suçun işlendiği ve bu nedenle 5237 sayılı TCK'nın 44. maddesinde düzenlenmiş bulunan farklı neviden fikri içtimanın şartlarının oluştuğu anlaşıldığı hâlde; sanığa, mağdur O'ya yönelik kasten yaralama suçuna göre daha ağır olan mağdur K'ye yönelik kasten öldürme suçuna teşebbüsten ceza verilmesi, mağdur O'ya yönelik eyleminden ise karar verilmesine yer olmadığına ilişkin hüküm kurulması yerine, yazılı biçimde TCK'nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima hükmü göz ardı edilmek suretiyle gerçek içtima kurallarına göre" hüküm kurulmasını hukuka aykırı bulmuştur.

Çoğunluk görüşüne uymayan Daire Üyesi, ilk derece mahkemesi kararının onanması gerektiği yönünde görüş beyan etmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da ilk derece mahkemesinin verdiği mahkumiyet hükmünün onanması gerektiği gerekçesiyle, Dairenin söz konusu kararına itiraz etmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise, aşağıdaki gerekçe ile Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararı doğrultusunda içtihatla bulunmuştur:

"... TCK'nın 43. maddesinin 3. fıkrasındaki; "Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz" hükmüyle, bu suçlarda zincirleme suç hükümleri ile aynı neviden fikri içtima kuralının uygulanmayacağı, dolayısıyla sayılan bu suçlarda, failin mağdur sayısının ayrı ayrı cezalandırılacağına ilişkin istisna hükmüne TCK'nın 44. maddesindeki farklı neviden fikri içtima düzenlemesinde yer verilmemiş olması, kıyas veya genişletici yorum yoluyla, hakkında düzenleme olmayan bir ceza hukuku konusunda kişi hak ve hürriyetlerinin aleyhine uygulama geliştirilemeyeceği yönündeki evrensel hukuk ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde, bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 44. maddesinin uygulanması ve meydana gelen suçların

kate alındığında, bu kabulün sorunlu olduğu düşüncesine ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle, **olası kastla işlenen suçlarda da teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi gerekir**. Ancak, bu durumda sorumluluğun sadece ortaya çıkardığı neticelerle sınırlı tutulması gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay bir kararında olası (muhtemel) kastla işlenen suçlarda da teşebbüs hükümlerinin uygulanması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur:

«Tabancayı düğün yerinde bulunan topluluğa doğru yatay ve hatta yukarıdan aşağı eğik durumda tevcih ederek müteaddit el ateş eden ve hayati nahiyeeden isabet sağlayan sanıkta öldürme bilinci ve muayyen olmayan öldürme kastının varlığı kabul edilmelidir. Sanığın normal bir insan boyundan daha aşağı bir seviyede topluluğa yönelterek yaptığı müteaddit atışlardan çıkan mermilerin kişi veya kişilere isabet edeceğini bilmesi gerekir. Bu itibarla olayda muayyen olmayan kastla adam öldürmeğe tam teşebbüste bulunmak suçu oluşur»⁹⁸¹.

III. Hazırlık ve İcra Hareketleri

Kasten işlenebilen bir suça teşebbüsten söz edebilmek için aranan birinci koşul, **gerçekleştirilen fiilin icra hareketi niteliğinde olmasıdır**. Bir suça teşebbüsten söz edebilmek için, en azından o suçun kanunî tarifindeki icra hareketlerine başlanmış olması gerekir. Bu nedenle, hazırlık hareketleri kural olarak cezalandırılmazlar.

Ancak, bunun bazı istisnaları mevcuttur. Hazırlık hareketi mahiyeti arzeden fiiller, kanunda suç olarak tanımlanmış olabilir. Meselâ, suç işlemek için örgüt kurulması, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından bir hazırlık hareketi mahiyetindedir. Keza, esas itibarıyla hazırlık hareketi mahiyeti arzeden bir fiille, başkasının işlediği bir suçun icrasına yardım eden (şerik) olarak iştirak etmek mümkündür.

en ağırlı olan kasten öldürme suçuna teşebbüsten ceza verilmesi, bunun dışında O'ya yönelik olası kastla yaralama suçundan ayrıca mahkûmiyet hükmü kurulmaması gerekmektedir.”

Aynı yönde içtihatlar için bkz. CGK, **16.9.2014**, E. 2013/9-431, K. 2014/377; CGK, **3.12.2013**, E. 2012/1-1569, K. 2013/575.

Buna karşılık, belirtilen durumlarda **gerçek ictima** hükümlerine göre cezaya hükmedilmesi gerektiği yönünde de içtihatla bulunulmuştur:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **10.12.2013** tarihli ve E. 2012/1-1572, K. 2013/600 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; S, kardeşi E'yi öldürmek kastıyla iki el ateş eder. Ancak, tabancadan çıkan mermi çekirdekleri E'ye isabet etmez; bunlardan biri E'nin hemen yanında bulunan yengesi L'ye isabet ederek yaralanmasına sebebiyet verir.

Önceki içtihatlarında olduğu gibi, suç sayısını **mağdur sayısına** göre belirleyen CGK, bu olayda, **gerçek ictima** hükümlerine göre ceza verilmesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur. Başka bir ifadeyle, CGK, bu olayda tek bir fiilin varlığını kabul etmemiştir. Sonucu itibarıyla doğru bulduğumuz bu içtihat, gerekçesi itibarıyla sorunludur.

⁹⁸¹ 1. CD; E. 1983/1812; T.24.5.1983, (YKD: Eylül 1983, sh. 1381-1382). Aynı yönde: 1. CD; E.1977/1438, K. 1977/2020, (YKD: Kasım 1977, sh.1620-1621).

Yeni TCK’da tanımlanan bazı suçlarda, **hazırlık hareketleri** dahi tamamlanmış suç gibi cezalandırılmayı gerektirmektedir. Örneğin, çocuklara yönelik fuhuş suçunun hazırlık hareketleri dahi, bu suç tamamlanmış gibi cezalandırılmayı gerektirmektedir (m. 227, f. 1). Keza, “Devletin güvenliğine –” veya “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”dan herhangi birini işlemek üzere iki veya daha fazla kişinin anlaşmaya varması, bu suçlar açısından bir hazırlık hareketi niteliğinde olmasına rağmen; Kanun koyucu bu durumu bağımsız bir suç olarak tanımlamıştır (m. 316).

Failin cezalandırılabilmesi için, gerçekleştirdiği hareketlerin işlemeyi kastettiği suçun icra hareketleri niteliğinde olması gerekir. Belli bir suçu işlemeye yönelik kastının herhangi bir şekilde tespit edilmiş olmasına rağmen, failin gerçekleştirdiği hareketler henüz icra hareketi niteliğine kavuşmamış ise, cezalandırılması cihetine gidilmeyecektir⁹⁸².

⁹⁸² Yargıtay CGK’nın **31.10.2012** tarihli ve E.2012/9-1234, K. 2012/1825 sayılı Kararında fiilin elverişliliği ile ilgili olarak doğru bulmadığımız açıklamaya yer verilmiştir:

“... teşebbüsün varlığından söz edilebilmesi için;

1- Kasıtlı bir suçu işleme kararı olmalı,

2- Elverişli hareketlerle suçun doğrudan doğruya icrasına başlanmalı,

3- Failin elinde olmayan nedenlerle suç tamamlanamamalı ya da sonuç gerçekleşmemelidir.

Bu(nlardan üçüncü) koşul açısından, yasadaki ifadeyle “elinde olmayan nedenler”den maksat **failin iradesi dışında gerçekleşen ve suçun tamamlanmasını engelleyen nedenler** olup, icra hareketlerinin bitirilmesinden ya da sonucun meydana gelmesinden önce ortaya çıkmalıdır. İcra hareketlerinin bittiği anın tespiti konusunda esas alınan ölçüt ise, yasa maddesinde düzenlenen tipik sonucun gerçekleşmesi açısından gerekli ya da yeterli bütün hareketlerin yapıp yapılmadığı hususudur. Bu konudaki araştırmada, **failin neticeyi gerçekleştirmek için yapmış olduğu hareketlerin suç tipi bakımından sonucu meydana getirmeye elverişli olup olmadığı belirlenecek ve elverişli olmadığı saptanırsa icranın bitmediği, aksi takdirde icranın bittiği kabul edilecektir.**

Böylelikle, suçun tamamlanmasından önce ve fakat hazırlık hareketleri aşamasından sonra gelen, başlanmış ama bitirilememiş bir eylemli evreyi ifade eden teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi için, **yapılan hareketlerin objektif olarak suçun yasal tanımında öngörülen sonucu meydana getirmeye elverişli olmasıyla birlikte, aracın fail tarafından bu sonucu gerçekleştirmeye uygun biçimde kullanılması, ancak failin elinde olmayan nedenlerle, icra hareketlerinin tamamlanamaması veya tamamlanmasına karşın sonucun gerçekleşmemesi gerekecektir.**”

Suçta teşebbüsten söz edilebilmesi için aranan şartlardan birisini, neticeli suçlarda gerçekleştirilen fiilin kanuni tarifte belirtilen neticenin gerçekleştirilmesi bakımından elverişli olması oluşturmaktadır. Şayet gerçekleştirilen fiil kanuni tarifte belirtilen neticeyi gerçekleştirmeye elverişli değilse, kanuni tarife uygun fiilin icrasından söz edilemeyecek ve dolayısıyla, suçun teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle faile ceza verilemeyecektir.

Oysa CGK’nın söz konusu kararında, şayet gerçekleştirilen fiil kanuni tarifte belirtilen neticeyi gerçekleştirmeye elverişli değilse, suçun “*icra(sı)nın bitmediği*” değerlendirilmesinde bulunulmuştur. Yani bu durumda fiil neticenin meydana gelmesi bakımından elverişli olmasa bile, faile ilgili suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle ceza vermek gerekecektir. Bu değerlendirmenin **yanlış** olduğunu belirtmekle yetiniyoruz.

Meselâ İstanbul'a gitmekte olan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan arama sonucunda bir yolcu (A) üzerinde ruhsatsız bir tabanca ile içinde başka bir şahsa (B'ye) ait adres ve sair bilgilerin yer aldığı bir not defteri bulunur. Yapılan araştırmada A ile B'nin aileleri arasında "kan davası" bulunduğu, B'nin A'nın kardeşini öldürmekten dolayı mahkûm olduğu tespit edilir. A, yapılan soruşturmada, B'yi intikam için öldürmek kararında olduğunu, bu amaçla gerekli bilgileri toplayıp, silah temin ettiğini ve İstanbul'a da bu nedenle gitmek istediğini açık bir şekilde söyler. Bu durumda, A'nın öldürmeye yönelik kastının varlığını şüpheye yer vermeyecek kesinlikte tespit edilmiş olabilir. Ancak, yakalanma anına kadar olan davranışları henüz kasten öldürmeye yönelik hazırlık aşamasında olduğundan, A'yı bu suça teşebbüsten dolayı cezalandırmamız mümkün olmayacaktır.⁹⁸³

Kişinin belli bir suçu işlemeye yönelik kastının tespit edilmiş olması, sorumluluğunun tayini için gereklidir. Ancak sadece kastının belirlenmesi, bu suça teşebbüsten dolayı sorumlu tutulması için yeterli değildir. Failin belli bir suçu işlemeye yönelik kastla gerçekleştirdiği davranışın aynı zamanda o suça ilişkin icra hareketi niteliği taşıması gerekir.^{984, 985}

⁹⁸³ Örnek için bkz. SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh.209/210.

⁹⁸⁴ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu'nun 22.5.2012** tarihli ve E. 2011/6-340, K. 2012/209 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, sanık "*mağdura ait işyerinin önüne gelen ve işyeri kepenginin altı adet asma kilidinden iki tanesini kırarak açan, diğerlerini de açmak için uğraşırken*" yakalanır. Yargıtay, bu olayda "*sanığın, mağdurun taşınır malını koruduğu egemenlik ve tasarruf alanına bizzat müdahale ederek, işlemek istediği hırsızlık suçunu gerçekleştirmeye elverişli hareketleri yaptığı, gece sayılan zaman dilimi içinde işyeri binasına hırsızlık amacıyla girmek için kepenk kilitlerini kırmak suretiyle suçun yasal tanımında, unsur ve nitelikli hal olarak belirtilmiş davranışları gerçekleştirerek elverişli hareketlerle doğrudan icraya başladığı kabul edilmelidir.*" içtihadında bulunmuştur.

Bu Kararı doğru bulmuyoruz. Bu olayda, hırsızlık yapmak amacıyla mağdurun işyerinin kepenk kilitleri kırılarak, **mala zarar verme suçu** tamamlanmıştır. Bu suretle ayrıca mağdurun **konut dokunulmazlığının ihlaline teşebbüs** edilmiştir. Bütün bu hareketler hırsızlık yapmak amacıyla icra edilmiş iseler de, hırsızlık suçunun icra hareketlerine henüz başlanmamıştır. Bütün bu hareketler **hırsızlık suçunun hazırlık hareketlerini** oluşturmaktadır.

Bir an için bu hareketler hırsızlık suçunun icrasına teşebbüs olarak değerlendirilse bile, olayda farklı neviden fikri ictima hükümlerini uygulayarak en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir. Başka bir ifadeyle, failin mağdura ait işyerinin kepenk kilitlerini kırması fiili, a) tamamlanmış mala zarar verme, b) konut dokunulmazlığının ihlali suçuna teşebbüs, c) hırsızlık suçuna teşebbüs olarak değerlendirilecektir. TCK'nın **farklı neviden fikri ictima** hükümleri (m. 44) gereğince, bir fiil üç ayrı suçtan dolayı ceza sorumluluğunu gerektirdiğinde, bunlardan sadece biri dolayısıyla ve fakat en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı failin cezalandırılması cihetine gidilecektir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararında olayda hırsızlık suçuna teşebbüsün varlığı kabul edildikten sonra, diğer **tamamlanmış mala zarar verme ve teşebbüs aşamasında kalmış konut dokunulmazlığının ihlali** suçlarından dolayı failin ceza sorumluluğu cihetine gidilip gidilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama ve değerlendirmeye yer verilmemiştir.

Bu mülahazatımıza rağmen CGK, 2.7.2014 tarihli ve E. 2013/6-507, K. 2014/340 sayılı Kararında aynı görüşe sadık kalmıştır:

“Kanunun benimsediği objektif teori esas alındığında, müştekiye ait işyerinin önüne gelen ve **işyeri kapı kilidini açmak için uğraşan sanığın**, müştekinin taşınır malını koruduğu egemenlik ve tasarruf alanına bizzat müdahale ederek, işlemek istediği **hırsızlık suçunu gerçekleştirmeye elverişli hareketleri yaptığı**, gece sayılan zaman dilimi içinde işyeri binasına hırsızlık amacıyla girmek için kapı kilidini açmaya çalışmak suretiyle suçun kanuni tanımında, unsur ve nitelikli hal olarak belirtilmiş davranışları gerçekleştirerek elverişli hareketlerle doğrudan icraya başladığı kabul edilmelidir.

Bu itibarla, açıklanan olayda hırsızlık suçuna teşebbüsün şartlarının oluştuğuna ilişkin Özel Daire bozma kararı isabetli olup, yerel mahkeme direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.”

Ancak, 13. Ceza Dairesi Başkanı Sayın DİRİM, görüşümüz doğrultusunda bu karara muhalefet etmiştir.

Bu uygulamaya sebebiyet veren anlayış, mülga 765 s. TCK’nın “bina içinde hırsızlık” olarak adlandırılan hırsızlık suçunun “ağırlaştırılmış” şekline ilişkin hükmünün (m. 491, f. 3, bent 4) etkisiyle oluşmuştur. Bu hükme göre, bina içine girilerek hırsızlık suçunun işlenmesi halinde ayrıca konut dokunulmazlığından dolayı cezaya hükmedilmemektedir; hırsızlık suçunun bu nitelikli halinden dolayı cezaya hükmedilmesiyle yetinilmekteydi. Bu nedenle, hırsızlık amacıyla binaya girmek veya girmeye teşebbüs etmek, hırsızlık suçunun bu nitelikli halinin icra hareketini oluşturmaktaydı. Yine bu anlayış, hırsızlık amacıyla konuta girerken mala zarar verilmiş olmasını, cezalandırma bakımından izahsız bir şekilde gözardı etmektedir.

Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nin 11.9.2014 tarihli ve E. 2013/33497, K. 2014/25197 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, F, hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı işyerinin asma kilitlerinden birini kırar ve fakat görülmesi üzerine ikinci kilidi kıramadan kaçır.

Daire’nin kabulüne göre bu olayda iki suç işlenmiştir. Bunlardan biri, teşebbüs aşamasında kalmış hırsızlık suçu; diğeri ise, yine teşebbüs aşamasında kalmış konut dokunulmazlığının ihlali suçudur. F, işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet vermiştir ve TCK, m. 44 hükmüne istinaden bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır. Bu nedenle F hakkında sadece teşebbüs aşamasında kalmış hırsızlık suçundan dolayı cezaya hükmetmek gerekir.

Dikkat edilmelidir ki, bu kararda da, hırsızlık amacıyla işyerine girmeye çalışılırken mala zarar verilmiş olması, cezalandırma bakımından izahsız bir şekilde göz ardı edilmiştir.

985 “Bir kimsenin suça teşebbüsten dolayı cezalandırılabilmesi için, **yapılan hareketlerin objektif olarak suçun yasal tanımında öngörülen sonucu meydana getirmeye elverişli olmasıyla birlikte**, aracın fail tarafından bu sonucu gerçekleştirmeye uygun biçimde kullanılması, ancak failin elinde olmayan nedenlerle, icra hareketlerinin tamamlanamaması veya tamamlanmasına karşın sonucun gerçekleşmemesi gerekir.”

Dava konusu olayda FF, 10.5.2006 günü saat 17.30 sıralarında polis merkezini telefonla arayarak, kardeşi MF’nin kendisini öldürmeye geleceğini bildirir. Bunun üzerine kolluk görevlileri, FF’nin evinin önüne giderek beklemeye başlar. MF, saat 18.00 sıralarında 54 promil alkollü olarak ve yanında sap kısmı 14 cm, metal kısmı 14,5 cm olan ekmek bıçağı ile olay yerine gelir. Kolluk görevlileri, daha evin önünde iken MF’yi yakalar ve bıçağa elkor.

Yukarıdaki “*açıklamalar ışığında* (söz konusu) *olay değerlendirildiğinde, sanık öldürmeye elverişli olduğu yönünde kuşku bulunmayan bıçakla ve öldürmek amacıyla mağdurun evine yönelmiş ise de, daha önceden evin önünde güvenlik önlemi alan kolluk güçlerince yakalanmış olup, Yasanın benimsediği objektif teori esas alındığında, bu hareketler öldürme suçu yönünden ancak **hazırlık hareketleri** niteliğindedir. O ana kadarki hareketlerin, doğrudan doğruya icraya başlama ölçütü çerçevesinde icra hareketleri kapsamında kabulü olanaksız*

dır. Özel Dairece benimsenen sübjektif teori kabul edilerek, eylemin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi, 5237 sayılı TCK'nın 35. maddesine açık aykırılık oluşturacağı gibi suçta ve cezada yasallık ilkesi ile de bağdaşmayacaktır.

Bu itibarla sanığın yakalandığı ana kadar ki fiillerini 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1. cümlesi kapsamında (tehdit olarak) kabul eden yerel mahkeme hükmü isabetli olup, Yargıtay C.Başsavcılığının bu yöne ilişkin itirazının kabulüne karar verilmelidir.”: CGK, 19.10.2010, E. 2010/1-153, K. 2010/206.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 5.2.2014 tarihli ve E. 2012/2733, K. 2014/1160 sayılı Kararına konu teşkil eden olay, şu şekilde cereyan eder:

S, uzaktan akrabası olan M ile evlenmek ister. Ancak M, bir başkasıyla evli olması sebebiyle, bu talebi kabul etmez.

S'nin bu amaçla kendisini sık sık rahatsız etmesi sebebiyle M, İstanbul'dan ayrılarak Afyon-karahisar'da oturan babası B'nin evine gider.

Bunun üzerine S, M'yi kaçırmak amacıyla özel aracıyla bir gece babasının evine gelir; kapıdan M'ye seslenir; balkona çıkan M'ye kendisini götürmek istediğini söyler. M, bu talebi kabul etmez.

M'nin bu cevabı karşısında S, içeri girmek için evin kapısını zorlar. Çıkan gürültü üzerine D, E ve F'nin de olay yerine gelmesi sebebiyle amacına ulaşamayacağını anlayan S, olay mahallinde bulunan bu kişileri tehdit eder, silahla havaya birkaç el ateş eder ve geldiği araçla olay mahallinden ayrılır.

Esas mahkemesi,

S'nin;

1) M'ye karşı,

a) **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma** suçunu (TCK, m. 109, f. 1) işlediğini,

b) bu suçu **silahla** (TCK, m. 109, f. 3, bent a) işlediğini,

c) işlediği bu suçun **teşebbüs** aşamasında kaldığını (TCK, m. 35),

2) D, E, ve F'ye karşı,

a) **tehdit** suçunu (TCK, m. 106, f. 1) işlediğini,

b) bu suçu **silahla** işlediğini (TCK, m. 106, f. 2, bent a),

c) bu suçu **bir fiille birden fazla kişiye karşı** işlediğini (**aynı neviden fikri içtima**: TCK, m. 43, f. 2)

kabul ederek, hakkında mahkumiyet hükmü tesis etmiştir.

Mahkeme, S hakkında her bir suçtan dolayı hükmettiği hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (CMK, m. 231, f. 5 vd.) vermediği gibi, bu hapis cezalarının ertelenmesine (TCK, m. 51) de hükmetmemiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, söz konusu olayda, **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından icra hareketlerinin henüz başlamadığı** ve bu nedenle S hakkında söz konusu suçta teşebbüsten dolayı cezaya hükmedilemeyeceği, ancak, açmak için kapının zorlanması suretiyle **konut dokunulmazlığının ihlali suçunun işlenişine teşebbüs edildiği** ve söz konusu suçun teşebbüs aşamasında kaldığı yönünde içtihatla bulunmuştur. Bu yönü itibarıyla Esas Mahkemesinin söz konusu mahkumiyet hükmü bozulmuştur. Bu yönü itibarıyla Daire Kararı doğrudur.

Ancak, söz konusu kararda; S'nin olay mahalline gelen D, E ve F'ye karşı tehdit ve silahla havaya ateş etme fiilleri değerlendirilmemiştir.

S'nin tehdit ve silahla havaya ateş etmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarını işlemek amacıyla yönelik değildir. S bu fiilleri olay mahalline gelen D, E ve F'nin kendisine müdahale etmesini engellemek ve kaçabilmesini sağlamak için işlemiştir.

Ancak, bu durumda hazırlık hareketleri ile icra hareketlerinin ayırımı meselesiyle karşı karşıya gelmekteyiz⁹⁸⁶. Daha açık bir ifadeyle; gerçekleştirilen hareketlerin suçun kanunî tarifindeki fiilin icrası cümlesinden olan hareketler mi yoksa hazırlık hareketleri mi teşkil ettiği hususunun tayini, ceza hukukunun tartışmalı konularından birini oluşturmaktadır.

Bir davranışın belli bir suça ilişkin icra hareketi niteliğine sahip olup olmadığının belirlenmesi, ancak objektif bir ölçütle mümkün olabilir.

Bu hususta şöyle bir yol izlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Suçun kanunî tarifindeki fiilin icrasına ilişkin hareketler şayet bu tanımda ayrıntılı olarak belirlenmiş ise; bu hareketlerin hepsi icra hareketleri olarak nitelendirilmelidir⁹⁸⁷. Meselâ, cinsel saldırı kastıyla mağduru etkisiz kılmaya yönelik cebir veya tehdit uygulanmış, ancak cinsel ilişki henüz gerçekleşmemiş olsa bile cinsel saldırı suçunun (m. 102) icrasına başlanılmıştır.

Buna karşılık, suçun kanunî tarifinde muayyen bir neticeye kasden sebebiyet verilmesi hususu belirtilerek; bu neticenin oluşumuna sebebiyet verecek hareketlerin tarz ve mahiyetinin belirlenmesi cihetine gidilmemiş ise; o zaman *fiil hakimiyeti ölçütünü* kullanmak gerekir⁹⁸⁸. Serbest hareketli bir suç olan kasten öldürme suçunun basit şekline ilişkin kanuni tarifte (m. 81) ölüm neticesinin kasten gerçekleştirilmesi aranmış, ancak bu neticenin ne tarz ve mahiyette bir fiil ile icra edilmesi gerektiği hususunda herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Bu tür suçlarda; suçun kanunî tarifinde belirlenmiş olan neticenin gerçekleşmesinde tayin edici olan hareketler icra hareketi mahiyetindedir⁹⁸⁹. Buna karşılık, meselâ öldürmek için zehir satın alınması kasten adam öldürme suçunun hazırlık hareketi niteliğindedir⁹⁹⁰.

Bu nedenle, Esas Mahkemesi tarafından teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun silahla işlendiğinden bahisle, S hakkında TCK'nın 109. maddesinin birinci fıkrası hükmüne istinaden belirlenen cezanın aynı maddenin üçüncü fıkrasının a bendi hükmüne istinaden artırılması doğru olmamıştır.

Ancak, S'nin ayrıca **silahla tehdit** suçunu işlediği ve bu suçtan dolayı TCK'nın 106. maddesinin ikinci fıkrasının a bendi hükümleri çerçevesinde mahkum edilmesi yönündeki Esas Mahkemesi içtihadı doğrudur.

⁹⁸⁶ İÇER, Zafer: *Suça Teşebbüste Hazırlık Hareketleri ile İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması*, İstanbul, 2021, sh. 120 vd.

⁹⁸⁷ SOYASLAN, Teşebbüs Suçu, sh. 70/71; aynı yazar, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 270 vd.; SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 195, 211 vd.

⁹⁸⁸ Yeni TCK'na ilişkin Hükümet Tasarısında, hazırlık ve icra hareketleri ayırımıyla ilgili olarak sübjektif yönü ağır basan karma bir görüşe yer verilmiştir. Buna göre; gerçekleştirilen hareket, “şüpheye yer bırakmayacak şekilde” kastı belirtecek nitelikte ise, icra hareketidir. (m 37 ve gerekçesi).

⁹⁸⁹ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 273.

⁹⁹⁰ Zina suçunun kanunî tarifinde suç sayılan fiil, “zina fiili” idi. Ancak, hangi hareketlerin zina fiilini oluşturduğu hususunda kanunda bir sarahat mevcut değildi. Bu nedenle, doktrinde zina

Yeni TCK'nın sisteminde de, hazırlık ve icra hareketleri arasındaki ayırımın objektif bir ölçüye dayandırılması amacıyla, “**doğrudan doğruya icraya başlama**” ifadesi kullanılmıştır.

Madde gerekçesinde bu husus şu şekilde izah edilmiştir:

“Suça teşebbüs düzenlemesinde getirilen diğer bir yenilik, icra hareketlerinin başlangıcına ilişkindir. Bilindiği üzere icra hareketlerinin ne zaman başladığının belirlenmesi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla yakından ilgilidir. Eğer failin kastının şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkmasıyla icranın başlayacağı yolundaki sübjektif ölçüt kabul edilirse, kişinin düşüncesi ve yaşam tarzı dolayısıyla cezalandırılmasına varabilecek bir uygulamaya yol açılacaktır. Çünkü hazırlık hareketleri aşamasında da kastın varlığının şüpheye yer vermeyecek biçimde tespit edilebilmesi mümkün olup, böyle bir ölçüt hazırlık – icra hareketleri ayrımı konusunu bir kanıtama sorununu hâline getirmektedir. Diğer bir deyişle, suçun icrasıyla ilgisiz davranışlar dahi, suç kastını ortaya koyduğu gerekçesiyle cezalandırılabilecektir.

Açıklanan bu nedenlerle, Tasarıdaki “kastı şüpheye yer bırakmayacak” ölçütü madde metninden çıkartılmış ve bunun yerine “doğrudan doğruya icraya başlama” ölçütü kabul edilmiştir. Böylece işlenmek istenen suç tipiyle belirli bir yakınlık ve bağlantı içindeki hareketlerin yapılması durumunda suçun icrasına başlanılmış sayılacaktır.”

Yargıtay, çeşitli kararlarında hazırlık ve icra hareketi ayırımında maddi ölçütü esas almıştır.

Fail, «ırza geçmek için eve girmek suçunu işlemiş ve bu esnada karanlıkta uyumakta olan çocuğun üstüne basması ve evdekilerin uyanması üzerine ırza geçmek için hiç bir fiili teşebbüse girişemiyerek kaçmış olması hususunda ne gibi icrai hareketlerde bulunduğu sübut delilleri ile izah olunmaksızın bu suçlunun ırza geçmeye nakısan teşebbüs ettiği anlaşıldığından bahisle yazılı olduğu üzere karar verilmesi yolsuzdur.»⁹⁹¹.

fiili tanımlanırken “cinsel ilişki” kavramı kullanılmıştır. Ancak, hemen belirtelim ki, bu kavramla da neyin kastedildiği açık bir şekilde ifade edilmemektedir. Nitekim Yargıtay, bir kararında, iki kişinin bir araya gelmiş olmaları halinde de zina suçuna eksik teşebbüsün olduğu kanaatine varmıştır: «“Eşimle yanındaki arkadaşını vagonda suç üstü yakalatmak istiyorum” şeklindeki ... dilekçesinin gereği yapılmak için zabıtaya havale edilmesi üzerine, kendilerine nereye gittikleri ve evli olup olmadıkları sorulduğunda, arkadaş olduklarını, müştereken İzmir’e bahse konu 19 numaralı kompartımanda seyahat edeceklerini belirtmeleri üzerine, yapılan aramada H.İ.nin şahsi çantasında 35 cc.lik bir “cin” ve dört adet limon, iki adet de “nestle” çikolata çıktığı, sanığın içkiyi yolda içeceklerini beyan etmeleri üzerine; oluşa, gösterilen gerekçelere ve dosyadaki dayanaklara göre, zınaya eksik derecede teşebbüste bulunmak suçu tüm öğeleriyle oluşmuştur.»: CGK. 9.3.1987, 599/105 (Uygun/Savaş/Mollamahmutoğlu: Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara, 1987, sh. 91). Ayrıca, bkz. 5. CD., 30.3.1988, 1082/2650 (YKD, Mayıs 1989, sh. 470); 5. CD., 27.2.1989, 699/793 (YKD, Nisan 1990, sh. 608).

⁹⁹¹ 1. CD, 22.6.1935, 3671/1733 (Sözür, Suça Teşebbüs, sh. 214).

«Sanıkların müştekinin evinde hırsızlık yapmayı kararlaştırdıktan sonra D'nin gözcü kaldığı, M'nin ise bahçe duvarından atlayıp içeri girerek kapı üzerindeki asma kilidi söküp lambayı gevşettiği sırada, müştekinin karısının gelmesi üzerine kaçtıklarının ... anlaşılmasına göre eylemin (geceleyin bina içinde hırsızlık suçuna) eksik teşebbüs derecesinde kaldığı gözlemlenmeden beraatlerine karar verilmesi.. yasaya aykırıdır.»⁹⁹².

«Elindeki dirgeni vurmak üzere kaldıran sanığın eylemi eksik teşebbüs niteliğindedir.»⁹⁹³.

«Kaçırarak üzere mağdureyi yakalamak için peşinden koşmak icra başlangıcıdır.»⁹⁹⁴

«Balta ve bıçakla müştekiyi kovalamaktan ibaret eylem, yaralamaya eksik teşebbüs niteliğindedir.»⁹⁹⁵.

«Maznunlardan A ile M, doktor olmaları ve bir ameliyathanenin sahip ve müstahdemi bulunmaları itibarı ile, kürtaj fiilinin icrasına yeter bilgi ve ona salih vasıtalar esasen mevcut ve muntazar olup, bu hadisenin ihzarî hareketinin anlaşma ve ücretin tediyeinden ibaret kaldığı; (doktor ve hastabakıcıların gerekli ameliyatın ifası amacıyla hazır olduğu halde) mütearrızünaleyh ve fiilin müteessiri mevkiinde bulunan S'nin ameliyat odasına alınması, ... ameliyat ifasına müsait durumda (üzerinin) soyulması, ameliyat masasına yatırılması ve yüzüne münhasıran ameliyatta kullanılan narkoz maskesinin geçirilmesi ameliyesine başlanması gibi hareketlerin, maznunların maksat ve mukarrer olan çocuk düşürmeye matuf icraattan mahdud ve böylece kanun himayesinde olan haklar yakın tehlike ile karşı karşıya gelmiş, ... maznunların kasdının iltibasa meydan vermeyecek derecede icrasına girişilmiş ve teşebbüsün vücuduna esas olan mukaddeme-i icraîyenin hudutları aşılarak daha ileriye varıldığı tebarüz etmiş olduğu ve icra hareketinin sadece netice götürün son hareket olmayıp, mürekkep olan bir fiilin hareketlerinden yalnız birisinin icrasına tevessül edilmiş bulunmasının da teşebbüs suçunun tahakkukuna kafi geleceği ve müştekiyi soymak ve masaya yatırmakla başlayan hareketlere devam edilerek maksut olan ana rahminden çocuğun alınması ve anne hayatı ile irtibatının kesilmesi gibi maksut olan neticeyi veren hareketler ile cürmün tamam olacağının şüpheden varestedir»⁹⁹⁶.

⁹⁹² 6. CD, 1983/3846-4088 (Çağlayan. I, sh.672).

⁹⁹³ 2. CD, 1.4.1976, 1623/3047 (YKD, Ekim 1978, sh. 1731).

⁹⁹⁴ 5. CD, 16.2.1981, 3854/3911.

⁹⁹⁵ 2. CD, 6.10.1981, 6365/6559.

⁹⁹⁶ 1. CD, 16.7.1954, 1105/1202 (Sözür, Suça Teşebbüs, sh. 215/216).

«... Failin belirli bir suçu işlemek kastını iltibasa mahal bırakmayacak surette meydana koyan hareketlere icra hareketi demekle sakınca yoktur. Bu yönüyle sadece harekete bakılmamakta, hareketin dışında kalan hususlar, meselâ failin ikrarı, suçtan sonra takındığı tavır, geçmişi, kişisel durumu gibi hususlar nazara alınmaktadır. Sanığın, mağdureyi kamyonu ile تنها yere götürdükten sonra onu öpmesi, bacaklarını elleyip sıkması, edep yerini tutması (şeklinde tezahür eden) hareketleri hiç kuşkusuz ki, TCK'nın 415. maddesindeki (ırza) tasaddi (suçunu) oluşturan (hareketlerdir. Ancak, failin) bu hareketlerinden sonra yere inerek mağdureye kendisini takip etmesini söyleyip تنها bir yer aramaya başlaması icraî değil ihzarî hareketlerdir. Bunları ırza geçmeye teşebbüsün icraî hareketleri olarak kabul etmek mümkün değildir.»⁹⁹⁷.

Bu son kararda gösterilen gerekçeye ve varılan sonuca katılamıyoruz. Kararda icra başlangıcı konusunda kabul edildiği belirtilen “*kastının iltibasa mahal bırakmayacak surette*” ortaya çıkması ölçütüne rağmen, olayda cinsel saldırı (ırza tecavüz) suçuna teşebbüsün varlığının kabul edilmemesi bir çelişkidir. Halbuki, karara konu teşkil eden olayda failin gerçekleştirdiği hareketler, cinsel saldırı (ırza tecavüz) suçunun icraî hareketleri niteliğindedir⁹⁹⁸.

Yargıtay, bu sübjektif ölçüyü başka kararlarında da esas almıştır:

«“Eşimle yanındaki arkadaşını vagonda suç üstü yakalatmak istiyorum” şeklindeki ... dilekçesinin gereği yapılmak üzere zabıtaya havale edilmesi üzerine, kendilerine nereye gittikleri ve evli olup olmadıkları sorulduğunda, arkadaş olduklarını, müştereken İzmir’e bahse konu 19 numaralı kompartımanda seyahat edeceklerini belirtmeleri üzerine, yapılan arama da H.İ.nin şahsi çantasında 35 cc.lik bir “cin” ve dört adet limon, iki adet de “nestle” çikolata çıktığı, sanığın içkiyi yolda içeceklerini beyan etmeleri üzerine; oluşa, gösterilen gerekçelere ve dosyadaki dayanaklara göre, *zinaya eksik derecede teşebbüste bulunmak suçu* tüm öğeleriyle oluşmuştur.»⁹⁹⁹.

Olayın oluş biçiminden anlaşıldığı üzere, kararda tartışma konusu olan problem, “evli kadının zinası suçu”nun teşekkül edip etmediği hususudur. Bu kapsamda tartışılan mesele, “evli kadının zinası suçu”nun icra hareketlerinin ne zaman başladığının ve dolayısıyla, olayda (eksik) teşebbüsün mevcut olup olmadığının tayininden ibarettir.

⁹⁹⁷ CGK, 1984/5-98/378 (Önder/Özek, Ceza Hukuku Pratik Çalışma Gereçleri, 2. Bası, İstanbul, 1987, sh.195 vd.).

⁹⁹⁸ Bu kararın eleştirisi için bkz. SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 218.

⁹⁹⁹ CGK. 9.3.1987, 599/105 (Uygun/Savaş/Mollamahmutoglu: Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara, 1987, sh. 91).

Yargıtay, olayda “zina suçu”nun icra hareketlerinin başladığı ve faillerin “zina suçu”na (eksik) teşebbüsten dolayı sorumlu tutulması gerektiği doğrultusundadır.

765 s. TCK’nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerine göre¹⁰⁰⁰; “kadının zinası” suçunun teşekkülü için, evli kadının kocası olmayan başka bir erkekle rızasıyla “cinsel ilişkide bulunması” gerekir. Bu “cinsel ilişki” henüz gerçekleşmemiş olmakla beraber, gerçekleşmesi için, icraî hareketlere başlanmış olabilir. Bu bakımdan mesele, zina suçunun icra hareketlerinin ne zaman başladığının tayini olarak tezahür etmektedir. Evli kadın açısından suç olarak tanımlanan zina “cinsel ilişkide bulunmak” olarak tayin edilince, bu “cinsel ilişki”nin, henüz tamamlanmadan önceki oluşumu hareketleri bu suçun icra hareketleridir.

Bu genel tespitlerimizin ışığında karara konu teşkil eden olayda, şayet kişilerin *kastı* zina etmek ise, henüz zina suçunun icra hareketleri başlamadığı için, o ana kadarki hazırlık hareketlerinin “zina suçu”na (eksik) teşebbüs olarak cezalandırılmaması gerekirdi.

Ancak, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yeni kararlarında yeni TCK’nın teşebbüse ilişkin hükümleriyle uyumlu olmaya özen göstermektedir¹⁰⁰¹.

¹⁰⁰⁰ Eşlerin birbirlerine karşı olan **sadakat yükümlülüğünün ihlali** mahiyetini taşıyan zina, bu nedenle haksız fiildir ve Medeni Kanunda boşanma nedenleri arasında gösterilmiştir. Ancak, zinanın sadece bir boşanma nedeni oluşturan bir haksız fiil olarak kabulü, temel toplumsal kurum olarak ailenin korunması için yeterli görülmemiştir.

Anayasa Mahkemesi, 23.9.1996 tarih ve 15/34 sayılı Kararıyla (RG: 27.12.1996/22860, sh. 246 vd.) 765 s. Türk Ceza Kanununun “erkeğin zinası” suçunu tanımlayan 441’inci maddesini, “kadının zinası” suçunu tanımlayan 440’inci madde hükmü karşısında eşitsizliğe sebebiyet verdiği gerekçesiyle iptal etmiştir. Keza, bu iptalin neden olduğu boşluğu Yasama organının süresinde doldurmaması dolayısıyla ortaya çıkan ve daha ağır sonuçları olan eşitsizliği gidermek amacıyla, Yüksek Mahkeme, bu defa 23.6.1998 tarih ve 3/28 sayılı Kararıyla (RG: 13.3.1999/23638) yürürlükteki Türk Ceza Kanununun 440’inci maddesi hükmünü iptal etmiştir.

¹⁰⁰¹ “TCK’nın 35. maddesinin birinci fıkrasında; “*kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur*” şeklinde tanımlanan teşebbüsün varlığından söz edilebilmesi için;

1- Kasıtlı bir suç işleme kararı olmalı,

2- Elverişli hareketlerle suçun doğrudan doğruya icrasına başlanmalı,

3- Failin elinde bulunmayan nedenlerle suç tamamlanamamalı ya da amaçlanan sonuç gerçekleşmemelidir.

Suça teşebbüste fail, suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine karşın, elinde olmayan nedenlerden dolayı fiilini gerçekleştirememekte, bu durumda kişiye tamamlanmış suça oranla daha az ceza verilmektedir. Teşebbüs halinde hâkim önce cezanın belirlenmesindeki ölçülere göre temel cezayı tayin edecek, ardından hükümdeki sırayı takip ederek teşebbüs hükümlerini uygulayacaktır. Teşebbüs hükümleri uygulanırken de somut olayda ortaya çıkan zarar veya tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurularak teşebbüse ilişkin kanun maddesinde belirtilen sınırlar arasında bir ceza belirlenecektir.

...

IV. Elverişlilik Sorunu

Suçta teşebbüs için aranan ikinci koşul, **gerçekleştirilen fiilin neticeyi meydana getirmeye elverişli olmasıdır**. Bir suçun icrasına teşebbüsten söz edebilmek için, icrasına başlanılan fiilin, kanunî tarifte unsur olarak yer alan neticeyi gerçekleştirilmeye elverişli olması gerekmektedir.

Elverişlilik değerlendirmesi ancak fiil bakımından yapılabilir. Bir fiilin icrasında kullanılan araç da o fiile elverişsizlik karakterini kazandırabilir. Ancak, elverişliliğin belirlenmesinde salt araç göz önünde bulundurulamaz. Bu nedenle ki, madde metninde Hükümet Tasarısındaki “elverişli vasıta” yerine “**elverişli hareketler**” ibaresi kullanılmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 35. maddesinin gerekçesinde; 765 sayılı Kanundaki "eksik - tam teşebbüs" ayırımına son verildiği, bu ayırımın objektif bir ölçütünün bulunmadığı ve uygulamada birtakım tereddütlere yol açtığı belirtildikten sonra, getirilen diğer bir yeniliğin icra hareketlerinin başlangıcına ilişkin olduğu, "failin kastının şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkmasıyla icranın başlayacağı" yolundaki subjektif ölçütün kabul edilmesi durumunda kişinin düşüncesi ve yaşam tarzı dolayısıyla cezalandırılmasına varabilecek bir uygulamaya yol açılacağı, çünkü hazırlık hareketleri aşamasında da kastın varlığının şüpheye yer vermeyecek biçimde tespit edilebilmesinin mümkün bulunduğu, suçun icrasıyla ilgisiz davranışların dahi suç kastını ortaya koyduğu gerekçesiyle cezalandırılabilceği, o nedenle tasarındaki "kastı şüpheye yer bırakmayacak" kriterinin madde metninden çıkartılarak "doğrudan doğruya icraya başlama" ölçütünün kabul edildiği, böylece işlenmek istenen suç tipiyle belirli bir yakınlık ve bağlantı içindeki hareketlerin yapılması halinde suçun icrasına başlanılmış sayılacağı açıklanmış; ayrıca kullanılan aracın suçun kanuni tanımında öngörülen fiili meydana getirmeye elverişli olması gerektiği, ancak elverişliliğin sadece kullanılan araç bakımından değil, suçun konusu da dâhil olmak üzere bütün fiil yönünden bulunması gerektiği, bu nedenle maddeye, suçta teşebbüsün bu unsurunu tam anlamıyla ifade eden "uygun hareketler" kavramının dâhil edildiği belirtilmiştir.

Görüldüğü gibi 765 sayılı Kanunda icra hareketlerinin başlangıcı konusunda açık bir ifadeye yer verilmezken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda doğrudan doğruya icraya başlama ölçütü kabul edilmiştir. Ancak soyut olan bu kavramın nasıl anlaşılması gerektiği konusu açık olmayıp, cezalandırılabilen davranışın ne zaman başladığını belirlemek her zaman kolay değildir.

Genel olarak suçun dış dünyada oluşmaya başladığı süreç, "hazırlık hareketleri" ve "icra hareketleri" olmak üzere birbirinden farklı iki aşamaya ayrılmaktadır. Suçu işlemek için kullanılacak âletlerin üretilmesi ya da temin edilmesi, eylem yerinin araştırılması veya gözetlenmesi, eylemle ilgili çeşitli bilgiler toplanması, suç işlendikten sonra sorumlu tutulmayı önleyici tedbirler alınması, suçtan elde edilecek eşyalar için güvenli bir yer ayarlanması gibi fiiller hazırlık hareketleri olup, suç tipini oluşturan icra hareketlerinden önce gerçekleştirilen ve cezalandırılmayan davranışlardır.

Teşebbüs ise, suçun tamamlanmasından önce, fakat hazırlık hareketleri aşamasından sonra gelen, başlanmış ancak bitirilememiş bir eylemli aşamayı ifade eder. Bu kapsamda cezalandırılabilir davranışların, yani suçta teşebbüsün sınırlarının saptanması, diğer bir ifadeyle suç yolunda ilerleyen sanıkla ilgili olarak hangi andan itibaren ceza hukukunun devreye gireceği sorununun çözülmesi gerekmektedir.

... bir kimsenin suçta teşebbüsten dolayı cezalandırılabilmesi için, yapılan hareketlerin objektif olarak suçun kanuni tanımında öngörülen sonucu meydana getirmeye elverişli olmasıyla birlikte, aracın fail tarafından bu sonucu gerçekleştirmeye uygun biçimde kullanılması, ancak failin elinde olmayan nedenlerle icra hareketlerinin tamamlanamaması ya da tamamlanmasına karşın, sonucun gerçekleşmemesi gerekir.” CGK, 24.9.2013, E. 2012/14-1239, K. 2013-383.

Bir fiilin kanunî tarifteki neticenin meydana gelmesi açısından elverişli olup olmadığının tespitinde, bu fiilin gerçekleştiği şartlar (somut olay) göz önünde bulundurulmak suretiyle, yani *ex ante* bir değerlendirme yapılmalıdır¹⁰⁰².

Nitekim, Yargıtay da şu kararında bu gerçeğe işaret etmiştir:

«Fail tarafından kullanılan vasitanın, (neticeyi gerçekleştirmeye) kesin olarak elverişli bulunması gerekir. Vasitanın elverişli olup olmadığını tespit için işlenmek istenen suç, suçun işlendiği yer ve zaman, mağdurun durumu ve tüm koşullar nazara alınmalıdır.»¹⁰⁰³.

Bu itibarla, öldürmek kastıyla mağdura silahın etki mesafesi dışında bir uzaklıktan ateş edilmiş olması halinde; her ne kadar kullanılan silah soyut olarak değerlendirildiğinde öldürme suçu açısından elverişli bir araç ise de; failin icra ettiği fiil, somut olayın gerçekleşiş şartları itibarıyla, ölüm neticesinin meydana gelmesi bakımından elverişli değildir.

Buna karşılık, fail öldürmek kastıyla silahı mağdura yöneltir ve tetiği çeker; ancak, silah gerçekte boştur ya da dolu olmasına rağmen ateş almaz. Bu durumlarda, gerçekleştirilen fiil kasten öldürme suçu açısından elverişlidir. Ancak, icra hareketleri tamamlanamamıştır.

Failin sahip bulunduğu özel bilgi, elverişliliğin belirlenmesi açısından dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, meselâ hemofili hastası olduğu bilinen bir kişiye basit bir yara ikai, ölüm neticesini oluşturmak açısından elverişli harekettir¹⁰⁰⁴.

Bu itibarla, elverişliliğin/elverişsizliğin mutlak veya nispi olarak bir ayırıma tabi tutulmasını isabetli bulmamaktayız^{1005,1006}.

¹⁰⁰² ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 465, 466; ALACAKAPTAN, İşlenemez Suç, sh.110 vd.; SOYASLAN, Teşebbüs Suçu, sh. 99, 100, 110.

Ancak, *Dönmezer/Erman*, söz konusu değerlendirmenin *ex post* olarak yapılması gerektiği fikrindedirler (DÖNMEZER/ERMAN I, no. 603).

¹⁰⁰³ CGK, 4.6.1990, 5-101/156 (YKD, Kasım 1990, sh. 1701). Ancak, Yargıtay'ın şu kararları elverişlilik açısından doğru değildir:

«Sanığın av tüfeği ile 30 metre civarında ateş etmesi sonucu 25-26 adet saçma tanesinin mağdura isabet etmesi ve saçmaların sadece yüzeysel yaralar meydana getirip derine nüfuz etmemesi, adam öldürme bakımından vasıtada *mutlak imkansızlık* bulunduğunu göstermektedir.»: 1. CD., 26.4.1989, 871/1393 (YKD, Kasım 1989, sh. 1636).

«Sanığın olayda kullandığı çakı bıçağı, öldürmeye elverişli vasıta niteliğinde değildir.»: CGK., 24.3.1986, 1-579/134 (Sözür, Teşebbüs, sh. 189, dn. 131).

¹⁰⁰⁴ SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 152, 187; aynı mealde ALACAKAPTAN, İşlenemez Suç, sh.93/94, 123 vd.

¹⁰⁰⁵ SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 186 vd.; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 465. “Mutlak elverişsizlik” ve “nisbî elverişsizlik” ayırımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 273 vd.

¹⁰⁰⁶ Ancak, ifade edelim ki; Yargıtay, pek çok kararında elverişliliğin “mutlak” veya “nisbî” oluşuna göre bir ayırım yapmak suretiyle sorumluluğun tayini cihetine gitmiştir:

Eğer kişinin gerçekleştirdiği fiil, kanunî tarifte unsur olarak yer alan neticeyi gerçekleştirme açısından elverişsiz ise; bu davranış ceza hukuku yönünden önem taşımamaktadır¹⁰⁰⁷.

Ancak, belirtelim ki; icra edilen fiilin neticenin meydana gelmesi açısından elverişsiz olmasıyla, suçun konusunun yokluğu durumunu birbirine karıştırmak gerekir¹⁰⁰⁸.

Suçun **konusu** açısından, elverişsizlikten değil, **yokluktan** söz edilebilir. İşlenmek istenen suç açısından konu mevcut değilse, ortada **işlenemez suç** vardır¹⁰⁰⁹.

Meselâ, failin öldürmek kastıyla ateş ettiği kişi, daha önce başka bir sebeple ölmüştür. Fail, başkasına ait olduğu düşüncesiyle, gerçekte kendisine ait olan bir malı çalmıştır. Fail, çocuğunu düşürmek amacıyla bir kadının meselâ bel nahiyesine, karın boşluğuna çeşitli şekillerde fizikî güç tatbik etmiştir. Fakat, kadın gerçekte hamile değildir¹⁰¹⁰.

Bu nedenle, icra edilen fiilin elverişsiz olmasıyla suç konusunun yokluğunu birbirine karıştıran Yargıtay'ın şu kararında beyan ettiği görüşe katılmıyoruz:

«Olay günü geceleyin lokantaya para çalmak maksadıyla giren ve boş çekmecede para bulamayan fail şikâyet üzerine yakalanmıştır. Gerçekten failin cürmî hareketlerinin yöneldiği nesneye suçun maddi konusu denilmekte ve bu konu suç kastının kapsamı içinde kalmaktadır. Hırsızlıkta maddi konu, taşınır mal olup, suç anında varlığı veya yokluğu eylem sonrası değil eylem öncesi bir değerlendirmeye her olayın özelliklerine, normal

«Olay, sanığın öldürmek maksadı ile mağdurun içeceği suya koyduğu *zehir miktarının azlığı ve mağdurun zehirli suyu az miktarda içmesi sebebiyle* ölümün sanığın iradesi dışında meydana gelmemek suretiyle zehirleyerek öldürme cürmünün *nakıs teşebbüs* derecesinde kalmasından ibarettir. Kullanılan zehir öldürmeğe elverişli olup, ancak miktarın azlığından dolayı ölüm meydana gelmemiş ve böylece *vasıtada nisbî imkansızlık* dolayısıyla cürmün 61. maddede yazılı nakıs teşebbüs derecesinde kaldığının kabulü gerekli görülmüştür.» (CGK, 18.4.1938, 169/388 (Sözür, Suça Teşebbüs, sh. 188).

«Sanık tarafından suçta kullanılan zehirin 61. maddedeki elverişli vasıtalarından olduğu şüphesiz bulunmaktadır. Ancak, *miktarının mağduru öldürmeğe kafi gelmediğinin* anlaşılmasına göre; *vasıtada nisbî imkansızlık hali* bahis konusu olmaktadır. (Zehir yerine zararsız bir maddenin verilmesi gibi) *vasıtada kati imkansızlık* halinde teşebbüsün cezalandırılması mümkün değilse de; bu olayda olduğu gibi, *nisbî imkansızlıkta nakıs teşebbüs hükümlerinin uygulanması gerekli* görülmüştür.» 1. CD, 16.5.1963, 320/1134 (Sözür, Suça Teşebbüs, sh. 188).

¹⁰⁰⁷ SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 153.

¹⁰⁰⁸ Bu nedenle, suç konusunun yokluğunu da fiilin elverişsizliği kapsamında değerlendiren görüşe (SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 192) katılmıyoruz.

¹⁰⁰⁹ SOYASLAN, Teşebbüs Suçu, sh. 112; aynı yazar, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 278 vd.

¹⁰¹⁰ Ancak belirtelim ki; hamile olan bir kadının çocuğunu düşürmek için ıhlamur çayı içirilmesi ya da bir insanın büyü (sihir) gibi yollarla öldürülmek istenmesi olaylarında işlenemez suçtan değil, suçun icrasına yönelik olarak gerçekleştirilen hareketin elverişsiz olmasından söz edilir (Bu ayırımı göz ardı eden görüş için bkz. SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 153).

insanın deneyimlerine ve benzer olaylarda çoğunlukla görülen durum ve koşullara göre saptanılmak gerekir. Bu saptamada varılan olumsuz sonuç, yani maddi konunun *kesin olarak yokluğu*, işlenemez (muhal, imkansız) suç; olumlu sonuç, yani maddi konunun *nisbî yokluğu* ise eksik kalkışma aşamasında kalmış suç uygulamasına götürecektir. Olayımızda sanık ve arkadaşının girdiği lokantadaki çekmecede para bulunması, yukarıdaki deneyimlere göre doğal ve olağandır. O yüzden suç anında paranın çekmecede bulunmaması, maddi konunun niteliğine göre, mutlak değil nispi anlamda bir yokluğu ortaya çıkarttığından, olayda işlenemez suç bulunduğu ileri sürülemez ve *hırsızlığa eksik kalkışma* suçunu oluşturur.»¹⁰¹¹.

Bu kararda belirtilen görüş, kanımızca doğru değildir. Çünkü, suçun konusunun yokluğu açısından mutlak ve nisbî ayırımı yapılamaz. Somut olayın meydana geldiği şartların gözönünde bulundurulması suretiyle suçun konusunun mevcut olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Buna göre, somut olayda işlenmek istenen suçun konusu ya vardır ya da yoktur. Bu suçun konusu yoksa, farazî bir değerlendirmeye bu yokluğun “nisbî” olduğunu ve dolayısıyla, işlenmek istenen suça teşebbüsün gerçekleştiğini kabul eden bu görüş doğru değildir¹⁰¹².

Belirtilen nedenlerle, bu gibi olaylarda failin gerçekleştirdiği hareketin bağımsız bir suçu oluşturup oluşturmadığını tayin etmek gerekir. Meselâ, fail, hırsızlık amacıyla eve girer ve fakat evde alacak bir şey bulamaz. Bu durumda faili sadece konut dokunulmazlığını ihlâl suçundan dolayı sorumlu tutmak gerekir.

Fail, mağdurun yatağında uyumakta olduğunu zannederek silahıyla yatağa doğru birkaç el ateş eder. Ancak, gerçekte yatak boş olduğu için herhangi bir kimse yaralanmış veya ölmüş değildir. Bu durumda, meselâ ateşli silah bulundurmak suçundan dolayısıyla failin cezalandırılması mümkündür.

Keza, meselâ, içinde para olduğu zannıyla açılan mektup zarfının içinde para yoktur. Bu durumda, kanımızca, hırsızlık suçuna teşebbüsten dolayı cezalandırma yoluna gidilemez¹⁰¹³. Mektup zarfının açılmasıyla haberleşmenin gizliliği ihlâl edilmiştir ve ancak bu nedenle fail cezalandırılabilir.

¹⁰¹¹ 6. CD, 14.6.1983, 4019/5620.(YKD, Ekim 1983, sh.1543).

¹⁰¹² Suçun konusu bakımından “mutlak yokluk” ve “nisbî yokluk” ayırımına ilişkin bilgi için bkz. SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 278 vd., 301 vd.

¹⁰¹³ Ancak Yargıtay, çeşitli kararlarında bu gibi olaylarda hırsızlık suçuna nakıs teşebbüsün varlığını kabul etmiştir:

«Suç konusu mektubun alıcısı olan Dürdane, Almanya’da bulunan kocasının bu mektupla kendisine 200 mark gönderdiğini telefonla söylediğini, mektubu almadığı için parasının da eline geçmediğini bildirmesine göre; mektubu gönderen kişi dinlenerek zarfın içinde para bulunup bulunmadığı sorulmak (gerekir. P)ara olduğu tespit edildiği takdirde, sanığın fiilinin TCK’nın 491/3. maddesine uyan hırsızlık suçunu, aksi halde hırsızlığa *eksik teşebbüs* suçunu oluşturacağı» kabul edilmelidir: 4. CD., 9.10.1989, 5272/5973 (YKD, Temmuz 1990, sh. 1084). Ayrıca bkz. CGK, 25.6.1990, 5-157/200 (YKD, Eylül 1990, sh. 1381 vd. (1383).

Yine, hamile olduğu zannedilen kadının, çocuğunu düşürmek amacıyla, birtakım ameliyeye maruz bırakılması durumunda, kürtaj suçunun konusu mevcut olmadığı için bu suç oluşmayacak ise de; kasten yaralama suçunun oluştuğunu söylemek pekala mümkündür¹⁰¹⁴.

Bu tür olaylarda, failin, ilgili suç tanımıyla korunan hukuki değerleri tanımayan davranışları tezahür etmiş ve bu nedenle tehlikeli bir kişilik taşıdığı ortaya çıkmıştır. Ancak, işlenmek istenen suç açısından somut olayda suçun konusu bulunmamaktadır; başka bir deyişle, suçun maddi unsurlarından biri olan konu, somut olayda mevcut değildir.

Dolayısıyla, bu durumlarda failin, işlemeyi amaçladığı suça teşebbüs etmekten dolayı cezalandırılmasını doğru bulmamaktayız¹⁰¹⁵.

İşlenemez suçun varlığı halinde, kişi suç işlemek iradesini davranışlarıyla açığa vurduğuna göre; toplum açısından tehlikeli bir kişiliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Tehlikeli kişiliği ortaya çıkmış olan bu kişi hakkında arzettiği tehlikeliliğe oranla bir güvenlik tedbirine hükmedilmesi gerekir kanısındayız¹⁰¹⁶. Ancak, yeni TCK'ya bu yönde bir hüküm konulması hususunda başarılı olamadığımızı belirtmek gerekir.

V. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcrasının Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi

Suçta teşebbüs için aranan üçüncü koşul ise, **suçun icra hareketlerine başlanmış olmakla birlikte, failin “elinde olmayan nedenlerle” bu hareketlerin tamamlanamamış veya kanunî tarifteki neticenin gerçekleşmemiş olmasıdır.**

¹⁰¹⁴ Hamile olan K, cenini düşürmek için çeşitli yöntemlere başvurur; ancak sonuç alamaz; E'den bu konuda yardım ister. Yardımı kabul eden E, gerekli müdahalede bulunur. Rahim tahliye edilir. Ancak ceninin, bu tahliye sırasında değil, daha önceki tahliye girişimleri sebebiyle öldüğü anlaşılır.

Bu örnek olayda K'nın rahmi tahliye edilmeden önce cenin ölmüş olduğu için, E tarafından işlenen çocuk düşürtme suçu (TCK, m. 99) bakımından işlenemez suçtan söz etmek gerekir. Çünkü E tarafından gerçekleştirilen K'nın rahminin tahliyesine yönelik girişim sırasında cenin ölüdür. TCK'nın 99. maddesinde tanımlanan **çocuk düşürtme suçunun** konusu, hayatiyeti devam eden cenindir. Bu durumda, şayet K'nın sağlığı bozulmuş ise, E'yi sadece **kasten yaralama suçundan** dolayı sorumlu tutmak mümkün olabilir.

Karnındaki cenini tahliye etmek için daha önce kendiliğinden çeşitli yöntemlere başvurduğu ve bu sebeple cenin öldüğü için, K bakımından TCK'nın 100. maddesinde tanımlanan **çocuk düşürme suçunun** oluştuğunu kabul etmek gerekir.

¹⁰¹⁵ *Sözür*, işlenemez suç halinde failin cezalandırılmasına taraftar değilse de (SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 153); yukarıda iktibas ettiğimiz Yargıtay kararında benimsenen görüşün doğru olduğu kanısındadır: SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 151, 190; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi[2], sh. 323.

¹⁰¹⁶ Arzettiği bu tehlikelilik nedeniyle *Dönmezer/Erman*, faile, işlenebilen suça oranla daha hafif bir ceza vermek veya hiç ceza vermemek hususunda hakime takdir yetkisinin tanınmasının yerinde olacağı fikrindedirler (DÖNMEZER/ERMAN I, no. 605). Ayrıca bkz. Alman CK, § 23, f. 2; İsviçre CK., mad. 23.

765 s. TCK’da olduğu gibi, yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısında da benimsenen “tam” ve “eksik teşebbüs” ayrımı dolayısıyla, uygulamada somut olaylarla ilgili olarak güçlüklerle karşılaşilmektedir. Bu nedenle, suça teşebbüs açısından söz konusu ayırım terkedilmiştir.

765 s. TCK’nın sisteminde, suçun kanunî tarifindeki icra hareketlerinin tamamlanmamış olması durumunda, “*nakıs (eksik) teşebbüs*” söz konusuydu (m. 61).

Suçun icra hareketlerinin tamamlanmış olmasına rağmen, kanunî tarifteki neticenin gerçekleştirilememesi halinde ise, “*tam teşebbüs*” söz konusu olmaktadır (m. 62).

“Tam” ve “eksik (nakıs) teşebbüs” ayrımı, bu izahata göre pek kolay görünmekte ise de; uygulamada somut olaylarla ilgili olarak güçlüklerle karşılaşmıştır.

Doktrinde *Dönmezer/Erman*’a göre; fail şayet gerçekleştirdiği hareketlerin iz ve eserlerini tamamen yok etmek iktidarına sahipse, “*nakıs teşebbüs*”; buna karşılık bu iz ve eserleri yok etmek iktidarına artık sahip değilse, “*tam teşebbüs*” söz konusudur¹⁰¹⁷.

Buna karşılık, diğer bir ayırıma göre, kanunî tarifteki neticenin gerçekleşmemesi için failin icraya devam etmemesi yeterli ise, “*nakıs teşebbüs*”¹⁰¹⁸; aksi takdirde, yani failin daha başka hareketler yapması gerekli ise, “*tam teşebbüs*” söz konusudur. Bu değerlendirme, suçun kanunî tarifindeki maddi unsurlar dikkate alınmak suretiyle yapılmalıdır¹⁰¹⁹.

Meselâ, fail, mağduru öldürmek kastıyla silahıyla bir el ateş eder ve fakat silahta bulunan diğer mermileri elinde olmayan nedenle ateşleyemez. Ölüm neticesinin meydana gelmediği bu durumda, icra hareketleri tamamlanmış olduğu için, kasten öldürme suçuna “*tam teşebbüs*” söz konusudur. Keza, fail, mağduru öldürmek kastıyla havagazı musluğunu açık bırakır; fakat, üçüncü kişilerin mağduru kurtarması nedeniyle, ölüm neticesi meydana gelmez. Bu durumda da kasten öldürme suçuna “*tam teşebbüs*” söz konusudur¹⁰²⁰.

Kanunî tarifte neticenin ayrıca bir maddi unsur olarak gösterildiği suçlarda suçun tamamlanma anının tespitinde bir sorunla karşılaşılmaz. Meselâ, kasten öl-

¹⁰¹⁷ DÖNMEZER/ERMAN I, no. 572.

¹⁰¹⁸ Yargıtay, hırsızlıkta çalınan şeyin değerinin çok az olması halinde, “hırsızlık suçuna eksik teşebbüs”ün olduğunu kabul etmektedir: 6. CD, 21.3.1990, 1225/2265 (YKD, Eylül 1990, sh. 1407). Keza, Yargıtay, içinde para olduğu düşüncesiyle mektup zarfının açılması ve fakat, zarfın boş çıkması halinde; yine “hırsızlık suçuna eksik teşebbüs”ün olduğu düşüncesindedir: CGK, 25.6.1990, 5-157/200 (YKD, Eylül 1990, sh. 1381 vd. (1383); 4. CD, 9.10.1989, 5272/5973 (YKD, Temmuz 1990, sh. 1084).

¹⁰¹⁹ ÖNDER, Genel Hükümler II., sh. 451; SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 225; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 347.

¹⁰²⁰ DÖNMEZER/ERMAN I, sh. 442; SÖZÜER, Teşebbüs, sh. 225 ve 284 nolu dipnotta belirtilen yazarlar.

dürme suçunda ölüm neticesi meydana geldiği an suç da tamamlanmış, eğer bu netice meydana gelmemişse teşebbüs derecesinde kalmış olur.

Ancak, Yargıtay, bu hususta çelişkili kararlar vermiştir:

«Olayda sanıkların mağduru zehirleyerek öldürmek maksadı ile bütün icrai hareketleri tamamlamış ve fakat sanıkların ihtiyarında olmayan sebepten, mağdurun kusma ve bünyesinin mukavemeti dolayısıyla (ölüm neticesi meydana gelmemiştir. Bu durumda) suç *tam teşebbüs* derecesinde kalmıştır.»¹⁰²¹.

«Ekmeğe zehir katarak kocasını öldürmek isteyen (kişinin fiilinin), kocası tarafından ekmeğin yenilmediği nazara alınarak, *nakıs teşebbüs* (olarak) tavsifi ve o şekilde ceza tayin edilmesi doğrudur.»¹⁰²².

Bu ölçütlerin uygulanması halinde de, “tam teşebbüs – eksik teşebbüs” ayrımında uygulamada tatmin edici olmayan sonuçlarla karşı karşıya gelinmektedir. Şöyle bir örnekle mesele daha iyi anlaşılacaktır:

Fail, mağduru öldürmek kastıyla silahını ateşlemiş olsun. Birinci ihtimalde mermi mağdura isabet etmez; ikinci ihtimalde ise, mermi mağdura isabet eder ve ağır yaralanmasına sebebiyet vermesine rağmen, mağdur ölmez. Bu iki ihtimalde de suçun icra hareketleri tamamlanmış ve fakat, netice gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla, kasten öldürme suçu “tam teşebbüs” aşamasında kalmıştır. Bu çözümün tatmin edici olmaması dolayısıyladır ki; Yargıtay, öldürmek kastıyla ateş edilen şahsa mermilerin isabet etmemesi halinde, kasten öldürme suçuna “eksik teşebbüs”ün olduğuna karar vermiştir.^{1023,1024}.

¹⁰²¹ 1. CD., 26.12.1964, 1861/2624 (Sözür, Teşebbüs, sh. 190, dn. 132).

¹⁰²² 1. CD., 26.2.1937, 2141/760 (Sözür, Teşebbüs, sh. 190, dn. 132).

¹⁰²³ 1. CD., 31.10.1985, 3289/3749 (YKD, Ocak 1986, sh. 123). Genel olarak bu konudaki kararlar için bkz. SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 228; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/ SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 347 vd.

¹⁰²⁴ «Babası G ile kavga eden S’nin, av tüfeğine şevrotin mermisi doldurarak etkili mesafeden öldürmek amacıyla babasına ateş ettiği; mermilerin hedefe değil de, yerden 135 cm. mesafede kapı ve duvara isabet ettiği, bu sırada küçük kardeşi maktül R’nin, ağabeyi S’ye “ayıp oluyor, yapma abi” demesi üzerine sanığın “sen de ondan yanasın” diyerek iki el ateş edip kardeşi maktülü öldürdüğü; müteakiben babası G’ye yeniden iki el ateş ettiği ve yine isabet ettiremediği anlaşılmış olmasına rağmen;

A- S’nin vaki atışları sonucu babası mağdur G’nin yaralanmadığı ve fiili TCK’nın 450/1, 61. maddelerine temas ettiği, bu suçu eksik teşebbüs safhasında kaldığı halde; tam teşebbüs şeklinde kabulü ile, 62. maddenin tatbiki cihetine gidilmesi;

B- Maktül R’den hiçbir tahrik hareketi gelmemesine rağmen; TCK’nın 51. maddesinin uygulanması» hukuka aykırıdır: 1. CD, 28.6.1990, (YKD Ekim 1990, sh. 1548).

Karara konu teşkil eden olayda iki suç işlenmiştir:

1) S → G’ye karşı, kasten adam öldürme suçu. Fail ile mağdur arasında usul fîru ilişkisinin bulunması, kasten adam öldürme suçunun nitelikli unsurunu oluşturmaktadır (765 s. TCK, m. 450, f. 1).

Bu nedenledir ki, meselâ 1930 İtalyan Ceza Kanununda “tam – eksik teşebbüs” ayırımından sarfınazar edilmiş ve genel olarak bir teşebbüs hükmüne yer verilmiştir (1930 İtalyan CK, m. 56)¹⁰²⁵.

“Sırf hareket suçları”nda, suçun tamamlanmış mı olduğu ya da “tam” teşebbüs aşamasında mı kaldığının tayini konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir.

Doktrinde “sırf hareket suçları”na “tam” teşebbüsün mümkün olmadığı kabul edilmektedir¹⁰²⁶. Meselâ, hırsızlık suçu, malın bulunduğu yerden kaldırılması suretiyle zilyedin egemenlik alanına sokulması ile ani biçimde tamamlanır. Böylece alma unsuru gerçekleşir gerçekleşmez suç da tamamlandığı için, hırsızlık suçuna “tam” teşebbüsün mümkün olmaması gerekir¹⁰²⁷.

Yargıtay ise, bu suçlara da “tam” teşebbüsün mümkün olduğunu kabul etmektedir:

«Sanığın evi ile çaldığı tütün salacının bulunduğu mağdurun kapısı önü 25 m. olup sanığın bu salacı alıp savuşmakta olduğu sırada rastlanarak az

2) S → Kardeşine karşı, kasten adam öldürme suçu. Fail ile mağdur arasında kardeşlik ilişkisinin bulunması, kasten adam öldürme suçunun nitelikli unsurunu oluşturmaktadır (765 s. TCK, m 449, f. 1).

Birinci suçta kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır. Fail mağdura karşı müteaddit defa ateş etmiş olmasına rağmen, mağdur isabet almamıştır. Her ne kadar kasten adam öldürme suçunun icra hareketleri tamamlanmış ise de, netice gerçekleşmemiştir. Bu itibarla, teşebbüse ilişkin 765 s. TCK’ndaki düzenleme biçimi esas alındığında, olayda kasten adam öldürme suçunun “tam teşebbüs” aşamasında kaldığını söylemek gerekir. Ancak, Yargıtay, bu gibi durumlarda “eksik teşebbüs”ün oluştuğu kanaatindedir. Yargıtay, değerlendirme konusu yaptığımız kararda da aynı görüşüne sadık kalmıştır.

Haksız tahrik, kişinin maruz kaldığı haksızlığın kendisinde oluşturduğu gazap ve hiddetin etkisiyle irade kabiliyetinin en azından zayıflamasını ifade etmektedir. Kişi, maruz kaldığı haksızlığın kendisinde oluşturduğu gazabın etkisiyle, suç teşkil eden bir fiili işlemiştir. Bu gibi durumlarda, işlenen fiilin haksızlık muhtevasında bir azalma söz konusu olmaz. İşlenen fiil ile ilişkin olarak irade kabiliyeti zayıflamış olduğu için, failin bu fiil nedeniyle kusurunda bir azalma söz konusudur. Bu itibarla, haksız tahrik halinin genel mahiyette bir “hafifletici sebep” olarak kabulü isabetli değildir.

Kararda belirtildiği üzere, maktül R’nin hiçbir haksız fiili mevcut olmadığı için, Esas mahkemesince S’nin kasten adam öldürme suçundan dolayı cezasında haksız tahrik hükümlerine istinaden indirim yapılması doğru olmamıştır.

Olayda fail iki ayrı kişiye karşı iki ayrı kasten adam öldürme suçunu işlemiştir. Bu suçlardan birisi tamamlanmış adam öldürme suçudur; diğeri ise teşebbüs derecesinde kalmış adam öldürme suçudur. Dolayısıyla, gerçek içtima kuralları uygulanmak suretiyle faile ceza verilmesi gerekir. Açıkça anlaşılmamakla beraber, kararda benimsenen çözüm şekli de bu doğrultudadır.

¹⁰²⁵ SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 228, 234; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 350. Görüşüne katıldığımız *Soyaslan* da, bu çözüm şeklinin daha doğru olduğu fikrindedir (SOYASLAN, Teşebbüs suçu, sh. 141).

¹⁰²⁶ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 351; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 429.

¹⁰²⁷ DÖNMEZER, Kişilere, sh. 306.

sonra yakalanmış ve kastettiği yere götürmesi bundan faydalanması imkânı henüz doğmamış bulunması dolayısı ile hırsızlık suçu tamamlanmış sayılmaz. *Tam teşebbüs* derecesindedir.»¹⁰²⁸.

«Mağdurenin sokulduğu yerin inşa halinde üstü beton atılmış, pencereleri ve kapısı takılmamış çevre duvarları örtülü ve sıvasız bir inşaat olduğu, sanığın mağdureyi kucaklayıp bu inşaatla soktuğu sırada, baştan beri durumu izleyen tarafından çağrılan komşuların koşması üzerine sanığın mağdureyi bırakıp kaçtığı anlaşıldığına göre, fiil zorla kaçırmaya *tam teşebbüstür*.»¹⁰²⁹.

Suçta teşebbüs konusunda uygulamada karşılaşılan en önemli sorun, cezanın saptanmasında eksik teşebbüs, tam teşebbüs ayrımının esas alınmasıdır. Çünkü bu ayrım bakımından her olaya uygulanabilen objektif bir ölçüt bulunamamakta ve bunun sonucunda, adil olmayan bir cezalandırma ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, teşebbüste cezanın saptanmasında esas alınan “eksik teşebbüs” – “tam teşebbüs” ayrımı, yeni TCK’nın sisteminde kaldırılmıştır¹⁰³⁰. Suçun tamamlanmadığı durumlarda ceza miktarı belirlenirken, işlenen fiilin doğurduğu **zarar veya tehlikenin ağırlığı** dikkate alınacaktır¹⁰³¹.

¹⁰²⁸ CGK, 26.9.1960, 6-24/27 (Sözür, Suça Teşebbüs, sh. 230).

«Sanığın çaldığı arabayı tasarruf edebileceği alana götürürken yakalanması hırsızlık suçuna tam teşebbüsü oluşturur.»: 6. CD, 18.4.1989, 2807/3813 (YKD, Ekim 1989, sh. 1501).

«Başlangıçtan beri takip edilen sanıkların çalmak istedikleri mallarla birlikte yakalanmaları, fiilin tam teşebbüs derecesinde kaldığını gösterir.»: 6. CD, 27.8.1988, 6554/10132 (YKD, Aralık 1988, sh. 1705).

¹⁰²⁹ 5. CD, 27.1.1982, 170/173 (Sözür, Suça Teşebbüs, sh. 232).

¹⁰³⁰ Ancak, *Hafizoğulları*, yeni TCK’da da “tam teşebbüs” - “eksik teşebbüs” ayrımının korunulduğunu iddia etmektedir: HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 276 vd. Buna karşılık, *Yarsuvat/Bayraktar* ve diğerleri, “tam teşebbüs” – “eksik teşebbüs” ayrımının kaldırılması yönündeki “tercih(in), son derece hatalı ve ileride büyük karışıklıklara, yanlış anlamalara, adaletsizliklere sebebiyet verebilecek bir düzenleme tarzı” (?) olduğu fikrindedirler: YARSUVAT/BAYRAKTAR ve diğerleri, sh. 298. Hatta, *Bayraktar*’a göre, bu ayrımın kaldırılması, “aczin ifadesinden başka bir anlama gelmemektedir.”: BAYRAKTAR, Köksal: *Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Genel Bir Değerlendirme ve Genel Hükümler Üzerine Birkaç Eleştiri*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap (Türkiye Barolar Birliği Yayını), Ankara, Eylül 2004, sh. 33. Bu açıklamalar, bilimsel bir tespiti veya öngörüye dayanmaktadır.

¹⁰³¹ Teşebbüs aşamasında kalmış olan suçta, fiilin haksızlık muhtevasının belirlenmesinde sebebiyet verdiği zarar veya tehlikenin ağırlığı esas alınmaktadır. Bu nedendir ki, teşebbüs aşamasında kalmış olan suçtan dolayı faile verilecek ceza, tamamlanmış suçta nazaran daha azdır.

Artuk/Gökçen/Yenidünya’nın teşebbüs aşamasında kalmış suç dolayısıyla tamamlanmış suçta nazaran daha az ceza verilmesinin izahı yönünde yaptıkları açıklamalar sorunludur:

“Eğer teşebbüse tam suçun cezası verilecek olursa fail, bir kere icra başladıktan sonra vazgeçmeyi düşünmeyecektir. Çünkü vazgeçmekte hiçbir çıkarı yoktur. Halbuki teşebbüsün cezası tam suçtan az olduğundan fiile devam etmemekte, hiç olmazsa az ceza görmek bakımından failin çıkarı vardır.” (ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, İkinci Bölüm, §6, II, 1, dn. 22). Bu açıklamalarda teşebbüs ile gönüllü vazgeçme birbirine karıştırılmıştır.

Suçta teşebbüs halinde, 61. maddenin beşinci fıkrasına öngelen fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden bir indirim yapılacaktır. Bu ceza üzerinden suça teşebbüs nedeniyle Kanunun 35. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen miktar veya oranlarda indirim yapılırken, “**meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı**” göz önünde bulundurulmalıdır.

Dikkat edilmelidir ki, suçun işlenmesiyle “meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı” 61. maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince temel cezanın belirlenmesinde de dikkate alınan bir ölçüt oluşturmaktadır. Suç teşebbüs aşamasında kaldığı için, temel cezanın belirlenmesinde tamamlanmış suça özgü olarak kullanılan bu ölçüt dikkate alınmayacaktır. Zira, suç teşebbüs aşamasında kaldığı için, “**meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı**” göz önünde bulundurulurken, Kanunun 61. maddenin beşinci fıkrasına öngelen fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden 35. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktar veya oranlarda indirim yapılacaktır. Aksi takdirde, mükerrer değerlendirme yasağı ihlal edilmiş olur.

VI. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu

Belli bir neticeye yönelik teşebbüs niteliğindeki hareketler de kanunda suç olarak tanımlanmış olabilir. Bu tür suçlara, **teşebbüs suçu** denmektedir. Örneğin, Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçu (m. 309), bu nitelikte bir suçtur. Ancak, belirtmek gerekir ki, madde gerekçesinde de vurgulandığı gibi, “*teşebbüs hareketlerinin bağımsız suç tipi olarak düzenlendiği (bu tür) suçlara teşebbüs mümkün değildir.*”¹⁰³²

Bazı suçlarda, **icra hareketlerinin belli bir aşamaya varması**, suç tamamlanmış olmasa bile, tamamlanmış suç gibi cezalandırılmayı gerektirmektedir. Örneğin, Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs edilmesi (m. 310, f. 1), rüşvet konusunda anlaşmaya varılması (m. 252, f. 3), uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin satışı arzı (m. 188, f. 3) hallerinde; ilgili suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunacaktır¹⁰³³.

VII. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara Teşebbüs Sorunu

Hemen ifade edelim ki, kesintisiz (mütemadi) suça da teşebbüs mümkündür.

Kanunî tarifindeki fiilin icrası süreklilik arzeden suçlara mütemadi suçlar denmektedir. Mütemadi suçlarda fiilin icrası bir süre devam etmektedir; suç işlenmeye devam etmektedir. Bu suçlar bakımından özellik arzeden husus, neticenin değil, fiilin icrasının devam etmesidir.

¹⁰³² Ayrıca bkz. SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 324 vd.

¹⁰³³ Keza, TCK’nın “*Göçmen kaçakçılığı*” suçunun tanımlandığı 79. maddesinde 22.7.2010 tarihli ve 6008 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte, bu suç *teşebbüs suçu* olarak tanımlanmıştır. Buna göre, söz konusu “*suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.*” (f. 1 ikinci cümle).

Mütemadi suça teşebbüs özellik taşımaktadır. Mütemadi suçlarla ilgili olarak **suçun tamamlanması** ve **bitmesi** kavramları kullanılmaktadır. Mütemadi suç tamamlanmaya kadar, suça teşebbüse ilişkin hükümler uygulanabilir. Buna karşılık suç tamamlanmış olmakla birlikte, icrasına devam ederken failin elinde olmayan nedenlerle icrasının sona erdirilmiş olması halinde, artık teşebbüse ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu durumda suç tamamlanmıştır. Örneğin kaçırılmak istenen kişiye karşı cebir veya tehdit uygulanmasına rağmen, kişinin direnç göstermesi nedeniyle bu suç tamamlanamamış olabilir. Bu gibi durumlarda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu (m. 109) teşebbüs aşamasında kalmış sayılır. Buna karşılık, kişi, cebir veya tehditle hürriyetinden bir süre yoksun bırakıldıktan sonra, güvenlik kuvvetlerinin olaya müdahalesi veya bir yolunu bularak kaçması sonucunda kurtulmuş olabilir. Bu durumda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu (m. 109) tamamlanmıştır ve fail tamamlanmış suçtan dolayı cezalandırılmalıdır.

VIII. İhmalî Suçlara Teşebbüs Sorunu

TCK'nın **teşebbüse ilişkin hükümleri** ancak icraî davranışla işlenen suçlar bakımından uygulanabilir. Başka bir deyişle, söz konusu hükümler, **ihmalî davranışla işlenen suçlar açısından uygulanamaz**. Bunun sonucu olarak, ihmalî suça teşebbüs, cezalandırılmaz. Meğer ki, kişinin ihmalî davranışı, başlı başına ceza yaptırımını gerektirsin. Bu bakımdan, örneğin durumu acil olan bir hastaya tedavi için vaktinde müdahalede bulunmayı kasten ihmal eden tabip, sonuçta ölümün meydana gelmesi halinde, ihmalî davranışla kasten öldürme suçundan (m. 83) dolayı cezalandırılmalıdır.

Buna karşılık, hastaya gerekli tıbbi müdahalede bulunmayı kasten ihmal eden tabibe rağmen, başka bir tabibin tıbbi müdahalesi sonucunda hasta iyileşmiş olabilir. Bu durumda, hastaya gerekli tıbbi müdahalede bulunmayı kasten ihmal eden tabip, kasten öldürme suçuna teşebbüsten dolayı değil¹⁰³⁴; gerçekleştirdiği ihmalî davranışın başka bağımsız bir suçu oluşturması halinde, bu suç nedeniyle sorumlu tutulmalıdır.¹⁰³⁵

¹⁰³⁴ Ancak belirtmek gerekir ki, doktrinde çoğunlukla *görünüşte ihmalî suçlara* teşebbüsün mümkün olduğu kabul edilmektedir (KUNTER, Suçun Maddi Unsurları, sh. 55; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 469; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 351; HAKERİ, Ceza Hukuku, 5. bası, sh. 154; aynı yazar: İhmalî Suçlar, sh. 266 vd.; aynı yazar: Kastan Öldürme Suçları, sh. 177 vd.). Buna karşılık, *Soyaslan* hem gerçek ihmalî suçlarda hem de görünüşte ihmalî suçlara teşebbüsün mümkün olduğu düşüncesine taraftardır (SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 328 vd.).

¹⁰³⁵ Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 17.5.2018 tarihli ve E. 2017/5844, K. 2018/5668 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, ehliyetsiz ve alkollü olan A, sevk ve idaresindeki araçla, gece vakti, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan B'ye çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet vermesine rağmen, durmayarak, yoluna devam eder. B, kaza sonrası olay mahalline gelen kişilerin yardımıyla hastaneye kaldırılır.

Bu olayla ilgili olarak İlk Derece Mahkemesi A hakkında **taksirle yaralamaya sebebiyet verme** (TCK, m. 88) suçu ile **yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi** (TCK, m. 98) suçundan dolayı ayrı ayrı mahkûmiyet hükmü kurmuştur.

Buna karşılık, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, taksirle yaralamaya sebebiyet veren A “*hakkında yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun kanuni unsurları oluşmadığından, (bu) suçtan beraat*” etmesi gerektiği gerekçesiyle, İlk Derece Mahkemesinin kurduğu mahkûmiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

(Aynı yönde diğer bir karar için bkz. Yargıtay 4. CD, **25.12.2015**, E. 2014/44736, K. 2015/40855)

Dikkat edilmelidir ki, bu olayda, A, B’ye çarptığının ve B’nin yaralandığının farkındadır. Buna rağmen durmayarak, yoluna devam eder.

Bu tür olaylarda, **ön gelen fiil dolayısıyla teminat yükümlülüğü** söz konusu olduğu için, sorunun TCK, m. 98’de tanımlanan yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu bağlamında ele alınması doğru olmamıştır.

Bu tür olaylarda, yaralanan kişinin bilahare ölmüş olması halinde, TCK, m. 83 hükümlerine istinaden ceza sorumluluğu söz konusu olacaktır (Bkz. Yargıtay 12. CD, **4.6.2013**, E. 2012/24745, K. 2013/15126).

Karara konu teşkil eden olayda ise B ölmemiştir, yaralanmıştır. Araç sürücüsü A, durumu fark etmesine rağmen, teminat yükümlülüğünün gereğini yerine getirmemiştir. Bu durumda sorunun, görünüşte ihmali suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanabileceği yönündeki görüş taraftarlarınca, **ihmali davranışla işlenen kasten öldürme** suçuna **teşebbüs** bağlamında ele alınması gerekir. Görüşümüze göre, ihmali suçlarda teşebbüse ilişkin hükümler uygulanamayacağı için, sorunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutmak gerekir.

Ölümlü, yaralamalı veya maddi hasarlı trafik kazalarında, kazanın oluşumu bakımından trafik kuralı ihlalinde bulunsun veya bulunmasın, kazaya karışan sürücünün aracının konumunu değiştirmemesi ve olay mahallini terk etmemesi gerekir.

Herhangi bir trafik kuralını ihlal etmiş olmasa bile, kazaya karışan araç sürücüsü,

“Kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise, bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmek”,

keza,

“Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak”,

yükümlülüğü altındadır (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, m. 81, f. 1, bent b ve d).

Ayrıca, herhangi bir trafik kuralı ihlal etmiş olsun veya olmasın, kazaya karışan araç sürücüsü *“kaza mahallinde ilk yardım önlemlerini alma(kla) ve en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber verme(kle) ve yetkililerin talebi üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürme”*kle yükümlüdür (2918 s. Kanun, m. 82, f. 1, bent a).

Karara konu teşkil eden olayda, trafik kazasına sebebiyet veren araç sürücüsü, **taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçunun** (TCK, m. 89) yanı sıra, 2918 s. Karayolları Trafik Kanunu, m. 81, f. 3’de tanımlanan **kaza mahallini terk etme, kaza mahallindeki durumu değiştirme, kaza ile ilgili olarak bildirimde bulunmama suçunu** işlemiştir. Yani bu gibi durumlarda araç sürücüsü hakkında iki ayrı suçtan dolayı gerçek içtima hükümlerine göre cezaya hükmetmek gerekir.

Bu durumda sorunu, TCK, m. 281’de tanımlanan **suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme** suçu bağlamında da değerlendirmek mümkündür. Ancak, trafik kazasına sebebi-

Örneğin hastaya gerekli tıbbi müdahale başka bir tabip tarafından gerçekleştirilmekle, ölüm sonucunun ortaya çıkması engellenmiş olabilir. Ancak, tabibin hastaya vaktinde gerekli tıbbi müdahalede bulunmayı kasten ihmal etmesi sonucunda hastanın sakat kalması gibi bir durum ortaya çıkmış ise, bu tabibi ihmali davranışla kasten yaralama suçunu (m. 88) işlemiş olması dolayısıyla sorumlu tutmak gerekir.

IX. Gönüllü Vazgeçme

İzlenen suç siyaseti gereğince, ceza kanunlarında, icrasına başladığı suçu tamamlamaktan vazgeçirmeye teşvik düşüncesiyle, gönüllü vazgeçme halinde faile ceza verilmemesi ilkesi benimsenmiştir. Bu yönü itibarıyla, gönüllü (kendiliğinden, ihtiyariyle) vazgeçme, bir **cezayı kaldıran şahsi sebeptir**¹⁰³⁶.

Gönüllü vazgeçme, yeni TCK'nın 36. maddesinde düzenlenmiştir:

“Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.”

Söz konusu maddenin **gereğince**nde şu açıklamalara yer verilmiştir¹⁰³⁷:

“Gerek icra hareketleri aşamasında gerekse icra hareketlerinin bitmesinden sonra, failin suçu tamamlamaktan gönüllü olarak vazgeçmesini teşvik etmek modern suç politikasının temel araçlarından biridir. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda sadece icra hareketlerinin devamı aşamasında kabul edilen gönüllü vazgeçme, icra hareketlerinin bittiği ancak neticenin meydana gelmediği olaylar bakımından da öngörülmüştür. Böylece suçun icrası sürecindeki bütün aşamalarda gönüllü vazgeçme mümkün hâle gelmektedir. Ancak icra hareketlerinin bitmesinden sonra gönüllü vaz-

yet veren kişi, kendi suçu ile ilgili delilleri yok etmesi, değiştirmesi veya gizlemesi halinde, bu suç bakımından **şahsi cezasızlık sebebinden** yararlanır m. 281, f. 1, ikinci cümle). Belirtmek gerekir ki, bu şahsi cezasızlık sebebi, 2918 s. Karayolları Trafik Kanunu, m. 81, f. 3'de tanımlanan kaza mahallini terk etme, kaza mahallindeki durumu değiştirme, kaza ile ilgili olarak bildirimde bulunmama suçuna teşmil edilemez.

Bu nedenlerle, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin vermiş bulunduğu bu karar, hukuka aykırıdır.

¹⁰³⁶ “persönlicher Strafaufhebungsgrund”: SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 240; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 58; JESCHECK, Lehrbuch (4), sh. 494, 498. Ayrıca bkz. SOYASLAN, Genel Hükümler 3. bası, sh. 291 vd.; KANGAL, Zeynel T.: “Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Gönüllü Vazgeçme”, in: Beiträge zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht, Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung, Baden-Baden 2010, sh. 344; aynı yazar: *Kişisel Cezasızlık Nedenleri ve Cezayı Kaldıran Veya Azaltan Kişisel Nedenler*, in: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi 2011, c: 7, sy: 85-86, sh. 51.

¹⁰³⁷ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 444.

geçmenin kabulü için, vazgeçenin suçun tamamlanmasını önlemek bakımından ciddi bir çaba göstermesi gerekmektedir.

Gönüllü vazgeçme hâlinde kişiye ceza verilmemekte, ancak o ana kadar yapılan hareketler ayrıca bir suç oluşturuyorsa sadece o suçtan sorumlu tutulmaktadır.

Suç bütün unsurlarıyla tamamlandıktan sonra örneğin çalınan eşyanın geri verilmesi veya kaçırılan kişinin serbest bırakılması hâllerinde, artık vazgeçme değil etkin pişmanlık söz konusudur. Bazı suçlarla ilgili olarak yapılan düzenlemeler bağlamında özel hükümler olarak etkin pişmanlığa yer verilmesinin daha doğru olacağı düşüncesiyle; Hükûmet Tasarısında “tam teşebbüs” aşamasındaki gönüllü vazgeçme karşılığında kullanılan etkin pişmanlıkla ilgili hüküm, Tasarı metninden çıkarılmıştır.”

Bu düşüncelerle ki; yeni TCK’nın 36. maddesinde gönüllü vazgeçme halinde, prensip olarak faile ceza verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, gönüllü vazgeçme anına kadar icra edilen hareketler müstakil bir suç oluşturuyor ise, fail bu suçtan dolayı cezalandırılacaktır.¹⁰³⁸ Meselâ, bulundurduğu ruhsatsız silah ile kasten öldürme suçunun icra hareketlerine başladıktan sonra bu suçu işlemekten ihtiyariyle vazgeçmesi halinde, faile ruhsatsız silah bulundurma suçundan dolayı ceza verilebilecektir. Keza, hırsızlık amacıyla konuta girildikten sonra, gönüllü olarak hırsızlık suçunun işlenmesinden vazgeçilmiş olabilir. Bu durumda, faili sadece konut dokunulmazlığını ihlâl suçundan dolayı cezalandırmak gerekir.

Vazgeçmenin **gönüllü** olması gerekir. Yani, herhangi bir engel olmaksızın, pişmanlık duyarak kişinin suçu işlemekten vazgeçmiş olması gerekir.

İçindeki parayı almak için kasayı açmaya çalışan ve fakat bunda başarılı olamadığı için vazgeçen kişinin bu vazgeçmesinin gönüllü olmadığına tereddüt yoktur. Ancak, meselâ, hırsızlık amacıyla konuta girmeye çalışırken köpeğin havlamaya başlaması üzerine vazgeçip kaçan kişinin bu vazgeçmesinin gönüllü olup olmadığını tartışmak gerekir. Kanımızca, bu gibi olaylarda kişi **yakalanmak korkusuyla** suç yolunda devam etmekten vazgeçmektedir. Bu gibi olaylarda, failde suçu işlemekten vazgeçme yönünde bir irade vardır; ancak bu irade zorlanmış bir iradedir ve dolayısıyla, gönüllü bir vazgeçmenin varlığını kabul etmek mümkün değildir¹⁰³⁹.

Bu durumla ilgili olarak Yargıtay kararlarından şu örnekler verilebilir:

765 s. «TCK’nın 62. maddesi hükmüne göre, suça yönelen eylemin tam teşebbüs derecesinde kaldığının kabulü için, sanıkta suç işlemek kastının

¹⁰³⁸ Aynı hüküm, gerek ’89 gerek ’97 Öntasarılarında dili sadeleştirilerek tekrarlanmıştır (m. 18, f. 2).

¹⁰³⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 246 vd.; SOYASLAN, Genel Hükümler 3. bası, sh. 287.

bulunması, suçta elverişli vasıtaların kullanılması, failin işlemeyi kastettiği cürmün icrasına ait bütün fiilleri bitirmesi ve fakat iradesi dışında bir sebepten dolayı o cürmün neticesinin meydana gelmemesi koşullarının gerçekleşmiş olması gerekir.

Burada Yasanın müeyyideye bağladığı suçun işlenmesine “mani sebep” failin dışında, iradesine yabancı bir sebeptir. Şayet tasarlanan eylemin gerçekleşmeme sebebi failin iradesine bağlanabiliyorsa, fail teşebbüs ettiği suçtan dolayı cezalandırılmaz. O ana kadar gerçekleşen eylemleri suç teşkil ediyorsa ona göre hüküm kurulur.»¹⁰⁴⁰.

765 s. «TCK'nın 62. maddesi hükmüne göre suça yönelen eylemin tam teşebbüs derecesinde kaldığının kabulü için aşağıda gösterilen koşulların gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. Sanıkta suç işleme kastının bulunması, suçta elverişli vasıtaların kullanılması, failin işlemeyi kastettiği cürmün icrasına ait bütün fiilleri bitirmesi ve fakat iradesi dışında bir sebepten dolayı o cürmün meydana gelmemesidir.

Burada yasanın müeyyideye bağladığı suçun işlenmesine (mani sebep) failin iradesi dışında, yabancı bir sebeptir.

Bu sebepler,

1- Maddi olabilir (üçüncü bir şahıs müdahalesi gibi).

2- Manevi olabilir (icra hareketlerinin failin iradesi dışında ve onu yabancı olan haller dolayısıyla bitirilmemiş olması gibi).

Şayet tasarlanan eylemin gerçekleşmeme sebebi failin iradesine bağlanabiliyorsa, fail teşebbüs ettiği suçtan dolayı cezalandırılmaz. O ana kadar gerçekleşen eylemleri suç teşkil ediyorsa ona göre hüküm kurulur.»¹⁰⁴¹.

«Mağdure ile aralarında duygusal ilişki bulunan sanığın, evlenmek amacıyla onu ana babasından istediği, olumsuz yanıt alması üzerine olay günü kiraladığı taşıta zorla bindirip kaçırdığı sırada, o *yalvarmaya başlayınca* başka bir dış etken olmadan sürücüye ve taşıtı durdurtup *mağdureyi özgür bıraktığı* toplanan kanıtlarla saptanmıştır.

Bu durumda (765 s.) TCK'nın 61/son maddesi gereğince tamam olan eyleminin sarkıntılık suçuna oluşturacağı gözetilmeden, beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.»¹⁰⁴².

«Doktor raporundan ciddi bir mukavemetin bulunmadığı anlaşılan mağdurenin, olay sırasında sanığa, “yapsan da yapmasan da kocama şikâyet

¹⁰⁴⁰ 5. CD, 24.4.1979, 1084/1086 (YKD, Şubat 1981, sh. 238 vd.).

¹⁰⁴¹ 5. CD, 26.10.1978, 2612/3146 (Sözür, Suça Teşebbüs, sh. 251/252).

¹⁰⁴² 5. CD, 3.7.1979, 2075/2035 (YKD, Ocak 1981, sh.104 vd.).

edeceğim” demesi üzerine sanığın bırakıp gitmesi, işlemeyi kast ettiği eyleminden kendi ihtiyarı ile vazgeçtiğini göstermektedir. Bu bakımdan sanığın tamamlanan eylemi (765 s.) TCK’nın 61/son maddesi karşısında sarkıntılık niteliğindedir.»¹⁰⁴³.

765 s. Kanundan farklı olarak, yeni TCK’nın sisteminde gönüllü vazgeçme, suçun icra hareketleri aşamasında olabileceği gibi, icra hareketlerinin tamamlanmasından sonra da mümkündür. 765 s. TCK’da ise, gönüllü vazgeçme sadece icra hareketlerinin devamı aşamasında kabul edilmiştir. 765 s. Kanuna göre “etkin pişmanlık” olarak nitelendirilen haller de bu sistemde gönüllü vazgeçme olarak kabul edilmiştir. Böylece suçun icrası sürecindeki bütün aşamalarda gönüllü vazgeçme mümkün hâle gelmektedir¹⁰⁴⁴.

Suçun icra hareketleri tamamladıktan sonra failin neticenin meydana gelmesini önlemesini ifade eden “etkin pişmanlık”la ilgili olarak 765 s. Kanunda hüküm bulunmamakla birlikte; doktrinde, 61. maddenin ihtiyariyle vazgeçmeye ilişkin ikinci fıkrası hükmünün kıyas yoluyla bu durumda da uygulanması gerektiği yönünde görüş ileri sürülmüştü¹⁰⁴⁵.

Buna karşılık, suçun tamamlanmasından önce “faal nedamet”ten söz edilmesinin doğru olmadığı, gönüllü vazgeçmenin teşebbüsün bütün aşamaları için geçerli bir müessese olarak düzenlenmesi gerektiği fikri ileri sürülmüştür¹⁰⁴⁶. Biz, teşebbüs açısından “tam teşebbüs” – “eksik teşebbüs” ayrımını doğru bulmadığımız için, bu görüşün yerinde olduğu kanısındayız^{1047, 1048}.

¹⁰⁴³ 5. CD., E.1974/664. K.1974/761, T.17.4.1974, 664/761 (Sözür, Suça teşebbüs, sh. 252/253).

¹⁰⁴⁴ *Hafizoğulları*, yeni TCK’nın, kişiyi bir suça ilişkin icra hareketlerini tamamladıktan sonra da gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlandırması dolayısıyla, “suçluluğa prim verdiğini” ve fakat, bu açıklamasıyla çelişir bir şekilde; örneğin öldürmek kastıyla mağdura ateş eden kişinin, mağduru yaraladıktan sonra pişmanlık duyarak yaşamasını temin için tedavi ettirmesi halinde kasten yaralama suçundan dolayı sorumlu tutulması gerektiğini kabul ettiğine göre, “objektif” sorumluluğu ortadan kaldırmadığını iddia etmektedir: HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 279.

¹⁰⁴⁵ BAYRAKTAR, Köksal: *Faal Nedamet*, İstanbul ÜHFM, cilt XXXIII, sayı 3-4, sh. 138 vd.; İÇEL/DONAY(3), sh. 87.

¹⁰⁴⁶ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 362; SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 246.

¹⁰⁴⁷ ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku (3), sh. 314.

¹⁰⁴⁸ Yeni TCK’na ilişkin Hükümet Tasarısında olduğu gibi, Öntasarı metinlerinde de genel bir hüküm olarak hem suçun tamamlanmasından önce hem de tamamlanmasından sonra faal nedamet müessesesine yer verilmiştir (’89 ve ’97 Metinleri, m. 20, f. 1; 2000 Metni, m. 39). Tasarı metnindeki düzenleme aynen şöyledir:

“Bir kimse, kasdettiği cürmün icra hareketlerini bitirmiş olmakla beraber çabalarıyla neticenin meydana gelmemesini sağlamış veya meydana gelmiş olan neticeyi tamamen ortadan kaldırmış ise, kanunda ayrı hüküm bulunmayan hallerde” suçun cezasında indirim yapılır (m. 39, f. 1).

Yeni TCK'nın sisteminde, gönüllü vazgeçme, gerek icra hareketleri aşamasında gerekse icra hareketlerinin bitmesinden sonra, failin suçu tamamlamaktan gönüllü olarak vazgeçmesini ifade etmektedir. Suçun icrası tamamlanıncaya, neticenin ayrıca bir unsur oluşturduğu suçlarda netice gerçekleşinceye kadar gönüllü vazgeçme mümkündür.

Bu bakımdan, örneğin öldürmek kastıyla mağdura ateş eden fail, mağduru yaraladıktan sonra etkin pişmanlık duyarak, ölmemesini ve tedavi edilmesini sağlamak için derhal hastahaneye kaldırır. Tedavi edilen mağdur, ölmekten kurtulur. Yeni TCK'nın sistemine göre, bu durumda fail kasten öldürme suçuna (m. 81 vd.) teşebbüsten dolayı cezalandırılmayacak ise de, mağdura karşı işlediği fiil kasten yaralama suçunu (m. 86 vd.) oluşturduğu için, bu suçtan dolayı cezalandırılacaktır^{1049,1050}.

Maddenin gerekçesinde şu ifadeler yer verilmiştir: “Böylece, harekete geçerek etkili bir surette neticeyi engelleyip veya bertaraf edip pişmanlığını aktif biçimde ortaya koyan kişinin bu tutumunun semeresiz kalmaması ve netice olarak sosyal savunmanın güçlendirilmesi öngörülmüştür. Uygun bir suç siyaseti, suçlunun yaptığı kötülüğü izale hususunda teşvik edici tedbirlerin getirilmesini ögütler” (’89 Metni, sh. 212; ’97 Metni, sh. 168; 2000 Metni, sh. 197).

Görülmektedir ki, bu düzenlemeye göre faal nedamet, bir *cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep* mahiyetini taşımaktadır.

Tasarının gerekçesinde yer verilen şu ifadeler de bu konuda izlenen suç siyasetini ortaya koymaktadır: “Şüphesizdir ki, bu gayretlerin neticesiz kalması, yani suçlunun harekete geçmesine rağmen neticenin bertaraf edil(e)memesi hali, sadece cezada takdiri bir (indirim sebebi) sayılabilecektir.” (’89 Metni, sh. 212; ’97 Metni, sh. 168; 2000 Metni, sh. 197).

¹⁰⁴⁹ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**’nun, **21.02.2012** tarihli ve E. 2011/1-692, K. 2012/60 sayılı Kararında, TCK’nın **gönüllü vazgeçmeye** ilişkin 36. maddesi hükümlerinin madde gerekçesine, doktrindeki görüşlere ve Yargıtay uygulamalarına dayalı olarak açıklaması yapıldıktan sonra, karara konu teşkil eden olayda aşağıdaki gerekçeyle failin gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlandırılması gerektiği içtihadında bulunulmuştur:

İcra hareketlerinin tamamlanmış olmasına rağmen neticenin gerçekleşmesinin engellenmesi bağlamında gönüllü vazgeçmenin varlığını kabul edebilmek için, “fail *kendi çabasıyla neticenin gerçekleşmesini* önlemelidir. Bunun için failin sonucun gerçekleşmesini önleyecek şekilde **gönüllülüğe dayanan aktif faaliyette** bulunması gereklidir.

Buna göre;

a) Fail sonucu önlemeye yönelik aktif davranışlarda bulunmalı ve bunun için ciddi çaba sarfetmelidir. Ancak aktif davranış, failin mutlaka kendisinin müdahalede bulunmak zorunda olması şeklinde anlaşılmamalıdır. Failin iradesine dayanan ve sonucu önlemeye yönelik bulunan her türlü çaba bu kapsamda olup üçüncü kişinin hareketi de, bu hareketin yapılmasına fail tarafından neden olduğu sürece yeterli kabul edilmelidir. Nitekim belirli bazı durumlarda sadece failin müdahalesinin sonucun gerçekleşmesine engel olmayacağı açıktır; bu kapsamda, fail tarafından ilk yardım ekibinin veya itfaiyenin çağırılması gibi neticenin meydana gelmesini engelleyen davranışların yapılması yeterli görülebilir.

Ciddi bir çabanın varlığından söz edebilmek için de failin içinde bulunduğu koşullarda sonucun gerçekleşmesini önlemeye yönelik mevcut olan bütün olanaklarını seferber etmesi gereklidir

b) Suçun tamamlanması, sözkonusu aktif davranışlar ve çabalarla önlenmelidir.

Böylece, icra hareketlerini tamamlayan failin, çaba göstererek neticenin gerçekleşmesini önlemesi durumunda gönüllü vazgeçme gerçekleşecektir.”

Somut olayda; “ağabeyine ait işyerinde, **mağduru öldürmeye yönelik olarak dokuz adedi yaşamsal tehlikeye neden olacak şekilde 24 yerinden bıçaklayan**, icra hareketlerini tamamladıktan sonra ve fakat ölüm sonucu gerçekleşmeden önce eyleminden dolayı pişmanlık duyarak **mağdurun yaralarına üzerindeki kıyafet ile tampon yapan, ambulans çağıran**, büro sahibi olan ağabeyine de **haber verip** onun da **ambulans çağırmasını sağlayan**, mağdura ulaşılması kolay olsun diye büro kapısını açık bırakan, bina görevlisine “*yukarıda yaralı var, hemen ambulans çağır*” diye söyleyerek onu da mağdur ile ilgilenmeye yönlendiren, olay yerine çok yakın bir yerden geçmekte olan emniyet ekiplerine yaralama olayını anlatarak adresi söyleyen, **mağdurun çok geçmeden hastaneye yetiştirilmesi ve ameliyat sonucu hayatının kurtulması için aktif eylemde bulunan** sanığın; öldürme suçunun icra hareketlerini tamamladıktan sonra, fakat ölüm sonucu meydana gelmeden önce iradi olarak aktif davranışlar ve ciddi çaba göstermek suretiyle, diğer etkenleri de harekete geçirerek kasten öldürme suçunun tamamlanmasını ve sonucun gerçekleşmesini önlediği anlaşıldığından, olayda TCK’nın 36. maddesinde düzenlenen **gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğunun** kabulü gerekmektedir.”

¹⁰⁵⁰ “Yargısal kararlarda, suç yolunda (iter criminis) ilerleyen sanık daha fazla ilerleme imkanına ve kanaatine sahip olduğu halde, suç yolunda ilerlemeyerek icrayı yarıda bırakmışsa ya da icra hareketleri tamamlandıktan sonra kendi çabası ile sonucun meydana gelmesini önlemişse vazgeçmenin gönüllü olduğu, buna karşılık fail icraya başlarken gözönünde tuttuğu ve hesaba kattığı risklerden başka bir faktör nedeniyle icra hareketlerine devam etmemişse ya da sonuca ulaşamamışsa vazgeçmenin gönüllü olmadığı, bu halde icra hareketleri failin elinde olmayan engelleyici nedenlerle bitirilemediğinden ya da sonuç failin elinde olmayan nedenlerle meydana gelmediğinden teşebbüsün sözkonusu olduğu vurgulanmıştır.

Gerek öğreti gerekse yerleşmiş yargısal kararlarda yer alan bu kabullere göre gönüllü vazgeçmenin varlığı için aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir.

- 1- Öncelikle kasıtlı bir suçun işlenmesine yönelik olarak icra hareketlerine başlanmalı,
- 2- Suç tamamlanmadan önce vazgeçme gerçekleşmeli,
- 3- Vazgeçmenin konusu; icra hareketinin devamına, suçun tamamlanmasına ya da sonucun gerçekleşmesine yönelik bulunmalı yani sanık ya suçun icra hareketlerinden vazgeçmeli ya da kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya sonucun gerçekleşmesini önlemeli,
- 4- Vazgeçme gönüllü olmalı yani fail suçun icra hareketlerini isteyerek terketmeli ya da suçun tamamlanmasını veya sonucun gerçekleşmesini isteyerek önlemeli,
- 5- Suçun tamamlanmasının önlenmesi veya sonucun gerçekleşmesinin engellenmesi, failin çabalarıyla meydana gelmelidir. Sonuç başka bir nedenle önlenmiş ise kural olarak gönüllü vazgeçme oluşmayacak ve fail 5237 sayılı TCK’nın 36. maddesinden yararlanamayacaktır.

Uyuşmazlık konusunun çözümüne yönelik olarak TCK’nın 36. maddesinde düzenlenen gönüllü vazgeçmenin ikinci şeklinin yani “*kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlemek*” biçiminin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçme halinden farklı olarak, sonucu gerçekleştirmeye elverişli ve yeterli icra hareketinin gerçekleştirilmesinden sonra gönüllü de olsa sadece icra hareketlerine devam edilmemesi yeterli olmayıp bunun yanında 5237 sayılı TCK’nın 36. maddesine göre fail, “*kendi çabasıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini*” önlemelidir. Bunun için failin sonucun gerçekleşmesini önleyecek şekilde gönüllülüğe dayanan aktif faaliyette bulunması gereklidir.

Buna göre;

a) **Fail sonucu önlemeye yönelik aktif davranışlarda bulunmalı ve bunun için ciddi çaba sarfetmelidir.** Ancak aktif davranış, failin mutlaka kendisinin müdahalede bulunmak zorunda olması şeklinde anlaşılmamalıdır. Failin iradesine dayanan ve sonucu önlemeye yönelik bulunan her türlü çaba bu kapsamda olup üçüncü kişinin hareketi de, bu hareketin yapılmasına fail tarafından neden olduğu sürece yeterli kabul edilmelidir. Nitekim belirli bazı durumlarda sadece failin müdahalesinin sonucun gerçekleşmesine engel olmayacağı açıktır; bu kapsamda,

Böylece, teşebbüs aşamasında gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık (faal pişmanlık, faal nedamet) ayırımı kaldırılmıştır.

fail tarafından ilk yardım ekibinin veya itfaiyenin çağırılması gibi neticenin meydana gelmesini engelleyen davranışların yapılması yeterli görülebilecektir.

Ciddi bir çabanın varlığından söz edebilmek için de failin içinde bulunduğu şartlarda sonucun gerçekleşmesini önlemeye yönelik mevcut olan bütün imkanlarını seferber etmesi gereklidir.

b) **Suçun tamamlanması, sözkonusu aktif davranışlar ve çabalarla önlenmelidir.** Böylece, icra hareketlerini tamamlayan failin, çaba göstererek neticenin gerçekleşmesini önlemesi durumunda gönüllü vazgeçme gerçekleşecektir.

Görüldüğü gibi, icra hareketlerinin bitmesinden sonra gönüllü vazgeçmenin kabulü için, vazgeçenin suçun tamamlanmasını önlemek bakımından ciddi bir çaba göstermesi ve sonucun bu nedenle meydana gelmemesi şart olarak aranmıştır.

İcra hareketlerinin terkedilmesi ya da suçun tamamlanmasının önlenmesi şeklinde gelişen her iki haldeki gönüllü vazgeçmede de, failin işlemekte olduğu suça ilişkin hareketleri teşebbüs aşamasında kaldığı halde, TCK'nın 36. maddesi uyarınca bu suçtan dolayı ceza verilemeyecek, işlemeyi kastettiği suça yönelik olarak vazgeçme ânına kadar icra ettiği hareketlerinin bir başka suçu oluşturması durumunda, o suçtan dolayı cezalandırılacaktır. Başka bir anlatımla gönüllü vazgeçmenin aynı zamanda tamamlanmış olan suçlara etkisi bulunmamaktadır. Vazgeçme sadece icra hareketlerine başlarken işlenmesi kastolunan suçu kapsamakta ve bu suça teşebbüsten cezalandırılmama sonucunu doğurmakta, ancak aynı zamanda tamamlanan başka bir suçun cezalandırılmasını engellemektedir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Sanığın olay günü yalnız yaşadığını bildiği komşusu katılanın kapısını çaldığı, katılan kapıyı açınca elinde eldiven olduğu halde üzerinden çıkardığı kesici kısmı 19 cm sap kısmı 13 cm uzunluğundaki mutfak bıçağı ile yaşlı olup hareket zorluğu çeken katılana vurmaya başladığı, katılanın bu şekilde bıçakla ikisi sırtta, birisi sol omuzda, birisi batında, birisi sağ aksiller bölgede, diğerleri ise baş ve boyun bölgesinde olmak üzere çok sayıda yerinden yaralandığı, bunlardan sol alt kadranda karın boşluğuna geçerek jejunum lezyonlarına ve jejunumun 80 cm'lik bölümünün alınmasına neden olan yaralanma ile sağ aksiller bölgede göğüs boşluğuna geçen **yaralanmanın hayati tehlikeye sebebiyet verecek nitelikte olduğu**, sanığın eylemleri sonucunda katılanın ağır yaralı vaziyette yere düştüğü, sanığın mutfakta aldığı başka bir bıçağı bükerek mağdurenin yanına bıraktığı, kendi getirdiği suçta kullandığı bıçağı ise görünmeyecek şekilde odadaki TV sehpasının altına altığı, eldivenleri de çıkartıp mutfaktaki sebzeliğin arkasına sakladığı, yerde yatan katılanın yanına gelerek *"Makbule teyze öldün mü?"* diye sorduğu, katılan *"Ölmedim"* deyince bu kez *"Beni şikayet edecek misin?"* diye sorduğu, katılan *"Yok"* diye cevap verince **katılanı o halde bırakıp kapıyı kapatarak evden ayrıldığı** ve kendi evine gittiği, evine geldiğinde ellerinde ve yüzünde kan olduğunu gören annesi ve ağabeyine *"Makbule teyzeye bir şey oldu, gidin bakın"* dediği, bunun üzerine annesi Fatma'nın katılanın kapısını çaldığı, katılanın sürünerek kapıyı açtığı, sanığın ağabeyi tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan katılanın acil ameliyata alınıp hayatta kaldığı olayda; sanığın suçta kullandığı bıçağı ve eldiveni saklayarak savunması doğrultusunda katılanın bıçak üstüne düştüğü algısını uyandırmak için mutfaktan aldığı başka bir bıçağı büküp mağdurenin yanına bırakması, sonra mağdurenin ölüp ölmediğini kontrol edip mağdureye *"Benden şikayetçi olacak mısın"* diye sorması, ancak katılanın şikayetçi olmayacağını söylemesi üzerine eylemine son vermesi, yaşlı ve ağır yaralı katılanı evde yalnız bırakıp kapıyı kapatması, ellerinde ve yüzünde kan olduğunu gören ağabeyi ve annesine mağdureye bir şeyler olduğunu söylemek dışında neticenin meydana gelmesini engellemek için hiçbir ciddi çaba içerisinde bulunmaması karşısında, **sanığın davranışlarının gönüllülüğe dayanmadığı gibi neticenin gerçekleşmesini önlemek bakımından ciddi bir çaba niteliğinde de olmadığından gönüllü vaz geçmenin şartlarının gerçekleşmediği** kabul edilmelidir.”: CGK, 11.07.2014, E. 2013/1-126, K. 2014/364.

Bu sistemde **etkin pişmanlık**, sadece **suç tamamlandıktan sonra** belli suçlar bağlamında **cezaı kaldıran** veya **cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep** olarak kabul edilmiştir^{1051, 1052}.

Gönüllü vazgeçme icrası devam eden, icrası henüz tamamlanmamış olan bütün suçlar bakımından söz konusu olabilir. Bu itibarla aleliltlak teşebbüs suçlarında gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanamayacağını ileri sürmek, tutarlılık arz etmez. Örneğin rüşvet suçu, bir teşebbüs suçudur. Söz konusu suç, rüşvet olarak mutabık kalan haksız menfaatin temin edildiği anda tamamlanmaktadır. Ancak, rüşvet konu-

¹⁰⁵¹ Yeni TCK'ndan etkin pişmanlıkla ilgili olarak şu örnekler verilebilir.

- Organ ve doku ticareti açısından (m. 93),
- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu açısından (m. 110),
- Malvarlığına karşı suçlar açısından (m. 168),
- İmar kirliliğine neden olma açısından (m. 184, f. 5),
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma açısından (m. 192),
- Parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları açısından (m. 201),
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu açısından (m. 221),
- Zimmet suçu açısından (m. 248),
- Rüşvet suçu açısından (m. 254),
- İftira suçu açısından (m. 269),
- Yalan tanıklık suçu açısından (m. 274),
- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu açısından (m. 281, f. 3),
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu açısından (m. 282, f. 6),
- Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu açısından (m. 289, f. 2),
- Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu açısından (m. 293),
- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçu açısından (m. 297, f. 4),
- Suç için anlaşma suçu açısından (m. 316, f. 2).

¹⁰⁵² «... Sanıklar, ... kaçıp kurtulamayacaklarını ve orman emvalinin istirdat edileceğini anladıklarından, sırf kendilerini kurtarmak amacıyla, ... orman emvalini kamyonlardan boşaltmışlardır. Her ne kadar TCK'nın 523. maddesinde öngörülen, mağdurun zararının karşılanması ise de; *istirdat edileceği muhakkak olan çalıntı malın terkedilmesi halini, rızai iadesinin varlığı biçiminde kabul etmek mümkün değildir...* Olayda rızai iade şartları gerçekleşmemiştir.» CGK., 4.2.1991, 6-364/6 (YKD, Aralık 1993, sh. 1864 vd. [1866]).

Ancak, Yargıtay'ın şu kararlarındaki görüşlere iştirak etmiyoruz:

«TCK'nın 523. maddesi, nedamete değil, tazmin esasına dayalı olup, mağdurun zararının giderilmesine yönelik bir düzenlemedir.

Kamu davasından önce işin Mahkemeye intikaline kadar geçen evrede vuku bulacak iade yahut tazminde, *iade veya tazminin sanık veya üçüncü kişi tarafından yapılması sonuca etkili değildir*. İstirdat dışında kalan iradî ve kastî her türlü iade veya tazmin, TCK'nın 523. maddesinin uygulanmasını zorunlu kılar.» CGK., 19.10.1992, 6-263/286 (YKD, Haziran 1993, sh. 924).

Hırsızlık suçunda, suçun mağdurunun zararının sanığın *babası tarafından* karşılanması halinde, «sanık hakkında TCK'nın 523/1. maddesinin ... uygulanması» gerekir. 6. CD., 30.10.1991, 5820/6889 (YKD, Şubat 1992, sh. 307).

sunda anlaşmaya varılması halinde de suç tamamlanmış gibi cezaya hükmedilir (TCK, m. 252, f. 3). Rüşvet konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen, rüşvet olarak anlaşılan miktar temin edilmeden taraflardan biri veya her ikisi rüşvetten vazgeçebilir. Bu durumda, gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri uygulamak gerekir. Keza, işinin gördürülmesi için rüşvet vermeyi teklif eden kişinin bu teklifi kamu görevlisi tarafından henüz ret veya kabul edilmeden önce, bu teklifinden vazgeçmesi, gönüllü vazgeçme hükümleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Keza, TCK, m. 277’de tanımlanan “*Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs*” suçu, adından da anlaşıldığı gibi bir teşebbüs suçudur. Bu suç, belirli bir hususta, belirli bir yönde karar verilmesi, görüş açıklanması veya beyanda bulunulması amacına matuf meramın söz konusu kişilere iletilmesiyle suç tamamlanmış olmaktadır. Ancak, bu durumdan, söz konusu suça teşebbüsün mümkün olmadığı ve dolayısıyla bu suçla ilgili olarak gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanamayacağı yönünde bir sonuç çıkarılamaz. Bir hakime hitaben yazılıp postaya verilmiş veya bir aracı marifetiyle gönderilmiş olan ve belirli bir yönde karar vermesini temin zımında meramı içeren mektubun, pişmanlık duyularak hakimın eline ulaşmasının engellenmesi halinde, gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

Hatta işaret etmek gerekir ki, belirtilen içerikteki mektubun içeriğine muttali olan aracı tarafından pişmanlık duyularak, muhatap hakime değil de, suç duyurusu zımında Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilmesi halinde, mektubu yazan kişi bakımından söz konusu suça teşebbüs etmekten dolayı cezaya hükmetmek ve aracı bakımından ise gönüllü vazgeçme hükümlerini uygulamak gerekir.

Anayasayı ihlâl suçu ile yasama organına ve hükümete karşı suçlar (TCK, m. 309, 311, 312), mahiyetleri itibarıyla teşebbüs suçudurlar. Bu suçların tamamlanması için, anayasanın değiştirilmiş olması, TBMM’nin veya hükümetin görevlerini kısmen de olsa yapamaması gibi bir neticenin meydana gelmesi gerekmez. Keza bu suçların işlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen hazırlık hareketleri, bağımsız bir suç olarak tanımlandığı için (TCK, m. 316), ancak “cebir ve şiddet” kullanılarak, bu suçların icrasına başlanabilir ve icraya başlamakla suç tamamlanmış olur. Madde gerekçesinde de vurgulandığı gibi, söz konusu suçlar bağlamında “*teşebbüsün ancak cebir veya tehdit kullanılarak, yani bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek gerçekleştirilmesi gerekir.*”¹⁰⁵³ Söz konusu suçların oluşabilmesi için, icra hareketlerine en azından başlanmış olmalıdır.¹⁰⁵⁴ Yani, cebri hareketlere bilfiil teşebbüs edilmiş olması, suçun oluşumu için gereklidir.¹⁰⁵⁵

¹⁰⁵³ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 698.

¹⁰⁵⁴ Yargıtay 16. CD, 14.7.2017, E. 2017/1443, K. 2017/4758, sh. 5.

¹⁰⁵⁵ ÖZGENÇ, Suç Örgütleri, 13. bası, sh. 278.

İcrasına başlanmış olan söz konusu suçların icra hareketleri işlenmeye devam ederken, yani icra hareketleri henüz sonuçlanmadan, kişiler gönüllü olarak bu suçları işlemekten vazgeçebilirler. Bu bağlamda vazgeçmenin gönüllü olup olmadığı her somut olayın koşullarına göre mahkemece takdir edilmesi gerekir. Başarısız olduğu artık anlaşılan bir darbe girişiminden vazgeçme halinde, gönüllülüğün söz etmek mümkün değildir. Ancak, darbe teşebbüsü henüz akim bırakılmadan önce, darbe teşebbüsünü bastırmaya yönelik fiziki güç kullanılmadan önce, bu girişimin içinde bulunan kişiler, çeşitli çağrılara icabet ederek, söz konusu suçların icrasına devam etmekten vazgeçebilirler. Bu koşullarda vazgeçmenin gönüllü olduğunu kabul etmek ve TCK'nın gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümlerini uygulamak gerekir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 22.3.2019 tarihli ve E. 2018/7103, K. 2019/1953 sayılı kararına konu teşkil eden olayda, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen “darbe teşebbüsü” çerçevesinde Gaziemir’den Çiğli 2. Ana Jet Üssüne gelen ve gerekli silah ve mühimmatla teçhiz edilmiş vaziyette pistte hazır bulunan iki helikopterin mürettebatı, bu harekâtın hukuksuz olduğunu anlayınca, kontrollerindeki helikopterlerin arıza yaptığı bahanesiyle, diğer suç ortaklarının sevk ve idaresindeki helikopterlere eşlik ederek havalanmazlar.

Dikkat edilmelidir ki, her ne kadar söz konusu darbe teşebbüsü bilahare akim kalmış ise de, pistte kalan helikopterlerin mürettebatı, giriştikleri fiilin icrasına devam etmekten herhangi bir zorlamaya binaen alıkonulmuş değildir.

Bu kişilerle ilgili olarak verilen beraat kararı sonuç itibarıyla doğru olmakla birlikte, Daire kararında yer verilen teşebbüs suçlarında gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı yönündeki açıklamalar, sorunludur.

X. Kabahate Teşebbüs

5326 s. Kabahatler Kanununun “Teşebbüs” başlıklı 13. maddesine göre; “*Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalandırılabilmesine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.*”

Madde gerekçesinde de “*Madde metninde, kabahatlere teşebbüsün kural olarak cezalandırılmayacağı kabul edilmiştir. Ancak, belli bir kabahate teşebbüsün de cezalandırılabilmesi konusunda ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklı tutulmuştur. Bu hallerde Türk Ceza Kanununun teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri uygulanacaktır.*” şeklinde açıklama yer almaktadır.

§21. Suça İştirak

I. Faillik

A. Çok Failli Suçlar

Davranış normlarıyla koruma altına alınan hukuki değerlere tecavüz teşkil eden ve bu nedenle haksızlık niteliği arzeden bazı insan fiilleri, kanunda *suç* olarak tanımlanmaktadır. Davranış normları ve bu normlar esas alınmak suretiyle vaz'edilmesi gereken (pozitif) hukuk kuralları, ontolojik vakıalara teleolojik bir perspektifle yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu metodolojik esastan hareketle, iştirak ilişkisi bir değerlendirmeye tabi tutulmakta ve bu değerlendirme neticesinde bazı tespitlerde bulunmaktadır¹⁰⁵⁶.

Bazı suçlar, zorunlu olarak ancak birden fazla kişinin müşterek katılımıyla gerçekleştirilebilirler. Genel olarak *zorunlu iştirak*¹⁰⁵⁷ diye adlandırdığımız bu halin söz konusu olduğu suçlardan bazıları, mahiyetleri gereği ancak birden fazla kişinin *fail* olarak katılımıyla gerçekleştirilebilirler. Biz, bu suçlara münhasır olarak, **çok failli suç** kavramını kullanmayı tercih ediyoruz.

Zorunlu iştirakin söz konusu olduğu diğer grup suçlarda, suçun işlenişi için yine birden fazla kişinin katılımı zorunluluk arzetmektedir; ancak, bu kişilerin hepsi fail değildirler. Suç tipini gerçekleştiren failin yanı sıra, suçun işlenişine zorunlu olarak iştirak eden diğer kişiler, ancak *şerik* olabilmektedirler. Bu tür suçlara biz, *zorunlu şerikliğin söz konusu olduğu suçlar* demekteyiz^{1058,1059}.

¹⁰⁵⁶ Suça iştirake ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Suç İştirakin Hukuki Esası ve Faillik*; İstanbul, 1996; ÖZGENÇ, İzzet: "Failliğin Üçüncü Bir Görünüş Şekli Olarak Müsterek Faillik", in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 4, yıl 1994, sayı 1-2, sh. 159 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: "Müsterek Faillik – Ceza Kanunu'nun 463. Maddesi Hükmünün ve Buna İlişkin Uygulamanın Değerlendirilmesi", in: Yargıtay Dergisi, cilt 19, Ocak-Nisan 1993, sayı 1-2, sh. 86 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: "Kavga Suçu (TCK., mad. 464) Üzerine Düşünceler" in: Yargıtay Dergisi, cilt 19, sayı 4, (Ekim 1993), sh. 477 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: "Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi" in: Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan 1999, sayı 1-2, sh. 70 vd.; ayrıca, Kamu Hukuku Arşivi, yıl 2, sayı 1, Şubat 1999, sh. 5 vd.; ÖZGENÇ/ŞAHİN, *Uygulamalı Ceza Hukuku*, sh. 319 vd.; İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER: *Suç Teorisi*, 2. kitap, İstanbul, 1999, sh. 372 vd.; ÖNOK, R. Murat: *Yapısal Suçlarda Failin Tespiti: Müsterek Suç Girişimi (Joint Criminal Enterprise) ve Örgütsel Hakimiyete Dayalı Dolaylı Faillik Doktrinleri*, Ankara, Mart 2019.

¹⁰⁵⁷ "Notwendige Beteiligung": MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 315; ayrıca bkz. DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1185.

¹⁰⁵⁸ Meselâ işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı yargılanmak üzere veya mahkûm olduğu cezanın infazı amacıyla aranan birini saklayan kişi, yeni TCK'nın 283. maddesinde tarif edilen suçun failidir. Ancak, bu kişinin sakladığı sanık veya mahkûm da, en azından saklanmayı kabul etmekle bu suça zorunlu olarak iştirak etmiştir. Hatta, bazı durumlarda sanık veya mahkûm, kendini saklaması için bu şahsı azmettirmiş olabilir. Sanık veya mahkûm, 283. maddede tanımlanan suçun işlenişine zorunlu olarak iştirak etmektedir; ancak, fail değildir; söz konusu suçun *zorunlu şeriki* durumundadır. Sanık veya mahkûmun bu iştirakinden dolayı cezalandırıl-

Birden fazla kişinin *fail* olarak katılımının zorunlu olduğu çok failli suçlar da, *yakınsama (tekarüb) suçları*¹⁰⁶⁰ ve *karşılaşma (telâki) suçları*¹⁰⁶¹ olmak üzere, iki gruba ayrılmaktadırlar.

Yakınsama suçlarında, zorunlu olarak suçun işlenişine katılımda bulunan kişiler, aynı yönden hareket etmektedirler ve aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemektedirler. Örneğin; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” (m. 220, f. 1: en az üç kişi), “Kamu görevinin terki veya yapılmaması” (m. 260, f. 1: en az dört kişi), “Hükümlü veya tutukluların ayaklanması” (m. 296, f. 1: en az dört kişi), “Devletin güvenliğine –” veya “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”dan herhangi birini işlemek üzere anlaşma (m. 316: en az iki kişi) gibi suçlar, ancak çok sayıda kişinin *fail* olarak katılımıyla gerçekleşebilen suçlardır. Bu tür suçlarda suçun işlenişine zorunlu olarak katılması gereken kişilerin hepsi, işlenen suçtan fail olarak sorumlu tutulacaklardır. Bunlar arasındaki ilişki, müşterek faillığe benzemektedir. Yani, bütün bu kişiler, suç teşkil eden haksızlığın gerçekleşmesi üzerinde müşterek hakimiyet kurmaktadır. Ancak, müşterek failliğin söz konusu olduğu suçlar bir kişi tarafından dahi işlenebildiği halde; yakınsama suçları ancak çok sayıda kişinin iştirakiyle gerçekleşebilmektedirler. Yakınsama suçlarının bu özelliği, söz konusu suçlara şerik olarak iştirak etmeye engel değildir. Bu suçlara azmettiren veya yardım eden olarak iştirak, her zaman mümkündür. Dikkat edilmelidir ki; söz konusu suçların işlenişine şerik

lip cezalandırılmayacağı meselesi, ayrı bir husustur. Bu konuda, iştirak kurallarından ziyade, ilgili suç tipinin mahiyeti gözönünde bulundurulmak suretiyle bir yargıya varılması, kanaatimizce, daha isabetlidir. (Nitekim bkz. ROXIN, Claus: Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, 10 Auflage, Vorbem. vor § 26, kn. 28; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 315; OTTO, Harro: Straflose Teilnahme, Festschrift für Richard Lange, 1976, sh. 211). Zorunlu şerikliğin söz konusu olduğu suçlara ilişkin diğer örnekler ve açıklamalar için bkz. OTTO, Lange-F., 211 vd.; ROXIN, LK[10], Vorbem. vor § 26, kn. 29 vd.; HERZBERG, Rolf Dietrich: Täterschaft und Teilnahme, München, 1977, sh. 133 vd.; LANGE, Richard: Die notwendige Teilnahme, Berlin, 1940, sh. 12 vd.; CRAMER, Peter: Schönke/Schröder(23), Vorbem. vor §§ 25 ff., kn. 49, 50; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 315 vd.; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 632/633; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 501/502.

¹⁰⁵⁹ Alman Hukukunda bütün bu ihtimalleri kapsayan bir kavram olarak yaygın bir şekilde "notwendige Teilnahme" ("zorunlu şeriklik") kavramı kullanılmaktadır. Ancak, bu kavramın, belirtilen bütün bu ihtimalleri kapsamadığı için, isabetli olmadığı da ileri sürülmektedir: LANGE, Die notwendige Teilnahme, Önsöz (Vorwort); OTTO, Lange-F., 197; ROXIN, LK(10), Vorbem. vor § 26, kn. 27; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 315; JESCHECK, Lehrbuch(4), 631; STRATENWERTH, Günter: Strafrecht, AT I, 3. Auflage, Köln/Berlin/Bonn, 1981, kn. 944; LÜDERSSEN, Klaus: Zum Strafgrund der Teilnahme, Baden-Baden 1967, sh. 65, dn. 89. Suçun işlenişine zorunlu olarak iştirak eden kişiler, her zaman *fail* olamayacağı için, Türk Hukukunda bütün bu ihtimalleri kapsayan genel bir kavram olarak, "çok failli suçlar" ibaresinin kullanılmasını da (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1185 vd.; ÖNDER, Genel Hükümler II, 500) isabetli bulmamaktayız. Keza, *Erem*'in kullandığı "toplu suçlar" (EREM, Faruk: Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, cilt I, 12. bası, Ankara, 1984, sh. 427) ifadesi de doğru değildir.

¹⁰⁶⁰ "Konvergenzdelikte".

¹⁰⁶¹ "Begegnungsdelikte".

(azmettiren veya yardım eden) olarak iştirak eden kişi(ler), suçun teşekkülü için katılımı zorunlu olan failer haricindeki kişi(ler)dir.

Karşılaşma suçlarında ise, zorunlu olarak suçun işlenişine katılanlar, yine aynı gayenin gerçekleşmesini hedeflemektedirler; fakat, bu defa aynı gayede birleşmek üzere farklı yönlerden hareket etmektedirler ve suçun işlenişine bulundukları katkılar da birbirlerinden farklı mahiyet arz etmektedirler. Karşıt, zıt istikametlerden ve farklı mahiyetteki katkılarla suçun işlenişine katkıda bulunan bu kişiler, işlenen suçun *faili* olarak sorumlu tutulacaklardır. Bu itibarla, suçun işleniş açısından fail olarak katılımı zorunlu olan bu kişilerin hiçbiri, söz konusu suçun mağduru olarak telâkki edilemez. Örneğin;

- a) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunda (m. 188, f. 3), birisi satan, diğeri satın alan olmak üzere,
 - b) Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda (m. 165), birisi satan veya bağışlayan, diğeri satın alan veya kabul eden olmak üzere,
 - c) Rüşvet suçunda (m. 252), biri rüşvet veren, diğeri rüşvet alan olmak üzere,
 - d) Rızaya dayalı kürtaj suçunda (m. 99, f. 2), biri çocuğu düşürten kişi, diğeri çocuğunun düşürülmesine rıza gösteren gebe kadın olmak üzere,
- en az iki kişinin varlığı gereklidir.

Karşılaşma suçlarına da ayrıca şerik (azmettiren veya yardım eden) olarak iştirak etmek mümkündür.

B. Suça İştirakin Hukuki Esası

Kanunî tarifte bir fiilin bir şahıs tarafından müstakilen gerçekleştirilmesi esas alınmaktaysa da, çoğu zaman bu fiiller birden fazla kişinin müsterek katılımı sonucu işlenmektedirler. Bu durumda, fiilin icrasına katılan suç ortaklarının hepsi de fiilin oluşumuna illî değeri haiz bir katkıda bulunmaktadırlar ve bu katkılarları nedeniyle sorumlulukları söz konusudur. Fakat kanun, bazı hallerde arzettiği özellik gereği bir suçun oluşumuna illî etkide bulunan bir katkıyı müstakil suç halinde düzenlemektedir. Bu tür iştirak şekilleri bazen kanunun suç olarak belirlediği bir fiilin daha önce başka kişi(ler) tarafından gerçekleştirilmesini zorunlu kılar ve buna istinat ederler. Meselâ, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (m. 165), suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (m. 281) gibi suçlar, icrası tamamlanmış bir suç sonradan iştirak niteliği arzetmelerine rağmen, müstakil bir haksızlık ifade etmeleri itibarıyla, ceza kanunlarında ayrı suçlar olarak düzenlenmişlerdir.

Hatta, bazen kanun bir suçun işlenmesine öngelen ve bu suç için hazırlık hareketi niteliği arzeden bir fiili, işlenen esas fiil açısından illî etkisi olmasına rağmen, bağımsız suç olarak düzenlemektedir. Meselâ, suç işlemeye tahrik (m. 214) ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma (m. 220) suçları, bu kabil suçlardandır.

Suçun iştirakin konusunu, bu istisnâî düzenlemeler dışında, birden fazla kişinin suç teşkil eden bir fiilin icrasına iştirak etmeleri halinde suç ortaklarının sorumluluk statülerinin belirlenmesi teşkil etmektedir.

Suç teşkil eden muayyen fiil, bir kişi tarafından müstakilen işlenebileceği gibi; birden fazla kişinin iştirakiyle de gerçekleştirilebilir. Bir suçun icrasına iştirak eden suç ortaklarının bu suçun işlenişine bulundukları katkıların normatif bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Bu itibarla, iştirak şekilleri, suç ortaklarının *sorumluluk statüleri* olarak nitelendirilmektedirler.

İştirak şekilleri genel bir şekilde **faillik** ve **şeriklik** olarak ikiye ayrılmaktadır¹⁰⁶². Bu sorumluluk şekillerinden faillik, kanunda tarif edilmiş haksızlığın gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Böylece, belli bir neticenin oluşumuna illî etkide bulunan herkes değil, ancak kanunda tarif edilen muayyen haksızlığı gerçekleştiren suç ortağı/ortakları *fail* olabilecektir: *Dar fail kavramı*.

Kanunî tarife uygun haksızlıktan birer *sorumluluk şekli* olarak gördüğümüz genel *faillik* - *şeriklik* ayırımından sonra, bu iki sorumluluk şekillerinin farklı görünüş biçimleriyle karşılaşmaktayız. Kanunda tarif edilen haksızlığı yalnız başına gerçekleştiren şahsa "**doğrudan -**" veya "**müstakil fail**" demektedir. Ancak, kanunî tariftaki bu haksızlık kişi tarafından doğrudan gerçekleştirilmeyebilir; yani, kişi suçu bir başkası vasıtasıyla gerçekleştirmiş olabilir. Bu durumda "**dolaylı faillik**" söz konusudur. Yine, kanunda tarif edilen haksızlık birden fazla suç ortağı tarafından müştereken gerçekleştirilebilir, ki bu durumda "**müşterek faillik**" bahis konusudur.

Suçun icrasına iştirak etmekle beraber, suçun işlenişine bulunduğu katkı suçun kanundaki tarifine uygun olmayan diğer suç ortaklarının da gerçekleşen haksızlıktan sorumlu tutulabilmeleri gerekir. Suçun işlenişine bulunduğu katkı kanunî tariftaki haksızlığı gerçekleştirmeyen diğer suç ortakları, **şerik** olarak nitelendirilmekte ve kanunun şerikliğe ilişkin genel hükümleri, **sorumluluk alanını genişleten hükümler** olarak telâkki edilmektedir. **Azmettirme** ve **yardım etme** olarak iki farklı tezahür şeklinin söz konusu olduğu şeriklikte, suç ortaklarının gerçekleşen kanunî tarife uygun haksızlıktan sorumlu tutulabilmeleri ancak **bağlılık kuralı** vasıtasıyla mümkün olabilecektir. Fail, gerçekleşen kanunî tarife uygun haksızlıkla, suçun objesiyle doğrudan temas halinde iken; şerik için böyle bir doğrudan temas söz konusu değildir. Şerik, faille olan şahsi bağlantısı nedeniyle ve ancak *bağlılık kuralı* vasıtasıyla söz konusu haksızlıktan sorumlu tutulacaktır^{1063, 1064}.

¹⁰⁶² ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 139 vd.

¹⁰⁶³ Kavram hakkında bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 141 vd., 316.

¹⁰⁶⁴ *Hafizoğulları*, bu temel felsefeye dayalı olarak yeni TCK'da yer alan iştirake ilişkin hükümlerin, hiçbir yenilik içermediğini ve hatta, iştirak müessesesini "kısırlaştırdığını" iddia etmektedir: HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 298 vd.

765 s. TCK'de, 1889 İtalyan CK'nda olduğu gibi, "aslî -" ve "fer'i iştirak" ayırımına yer verilmişti. Bunlardan failliğe tekabül eden "aslî iştirak", "maddi" ve "manevi" ayırımına, yani "aslî maddi iştirak", "aslî manevi iştirak" ayırımına tabi tutulmuştu. "Aslî maddi faillik" altında "fiili icra etme" ve "doğrudan doğruya beraber işleme" şeklinde bir ayırım öngörülmüştü. Buna karşılık *azmettirme*, "aslî manevi fail" olmayı gerektirmektedir (m. 64). Şerikliğe tekabül eden "fer'i iştirak" halleri ise Kanunun 65. maddesinde tek tek sayılmıştır. Şeriklik de "fer'i maddi iştirak" ve "fer'i manevi iştirak" olarak ikiye ayrılmıştı. Şeriklik halinde, kural olarak cezanın indirilmesi gerekmekteydi. Ancak "zorunlu şeriklik" halinde kişiye faille aynı cezanın verilmesi öngörülmüştü.

Yeni TCK'nın 37. maddesinin **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir¹⁰⁶⁵:

765 s. Kanunun suça iştirakle ilgili olarak benimsediği "sistemin en önemli sakıncası, kişinin suçun işlenişine katkısının, gerçekleştirilen suçun bütünlüğü içerisinde değil, ondan bağımsız olarak ele alınmasıdır. Örneğin bir işyerinde işlenen silahlı yağma suçunda, dışarıda gözcülük yapan kişinin fiili yağma suçunun bütününden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, gözcülük yapan uygulamada bazen "asli fail" bazen "fer'i fail" olarak sorumlu tutulmaktadır. Bu sistemde, suçun işlenişine iştirak eden kişilerin çoğu zaman "asli fail" olarak mı yoksa "fer'i fail" olarak mı sorumluluğu gerektirdiği duraksamaya yer vermeyecek bir biçimde saptanamamaktadır. Hâlbuki, örnek olayda gözcülük yapma fiilinin diğer kişilerle birlikte işlenen yağma suçunun gerçekleşmesine olan etkisi bir bütün olarak değerlendirildiğinde; gözcülük yapan kişinin de diğer suç ortaklarıyla birlikte suçun işlenişinde ortak hâkimiyet kurduğu sonucuna ulaşılır. Bu durumda ise gözcülük yapan kişinin de fail olarak sorumlu tutulması gerekir.

... Yeni yapılan düzenlemeyle, iştirak şekilleri, fiilin işlenişinde kurulan hâkimiyet ölçü alınarak belirlenecektir. Bu sistemde birer sorumluk statüsü olarak öngörülen iştirak şekilleri ise, faillik, *azmettirme* ve *yardım etmeden ibarettir*.¹⁰⁶⁶

¹⁰⁶⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 444 vd.

¹⁰⁶⁶ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun **2.2.2010**, tarihli ve E. 2009/1-239, K. 2010/14 sayılı Kararında iştirak müessesesinin hukuki mahiyetine ilişkin olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

"5237 sayılı Yasa ile asli iştirak-fer'i iştirak ayrımı kaldırılmıştır. Yasa gerekçesinde belirtildiğine göre; eski sistemin en önemli sakıncası, kişinin suçun işlenişine katkısının, gerçekleştirilen suçun bütünlüğü içerisinde değil, ondan bağımsız olarak ele alınmasıdır. Bu nedenle, 765 sayılı Yasanın yürürlükte olduğu dönemde uygulanan sistemde, suçun işlenişine iştirak eden kişilerin çoğu zaman asli fail olarak mı, yoksa fer'i fail olarak mı sorumlu tutulacakları duraksamaya yer vermeyecek biçimde saptanamamaktadır.

Yine gerekçede ifade edildiği gibi, Hükümet Tasarısı'nda da benimsenen asli iştirak, fer'i iştirak ayırımının adil ve eşit olmayan bir cezalandırmayı sonuçlaması ve uygulamada zorluk ve duraksamalara neden olması dolayısıyla, bu ayrımı esas alan düzenleme tasarıdan çıkarıl-

mıştır. Yeni yapılan düzenlemeyle, iştirak şekilleri **filin işlenişinde kurulan hakimiyet ölçü alınarak** belirlenecektir. Bu sistemde birer **sorumluluk statüsü** olarak öngörülen iştirak şekilleri ise, faillik, azmettirme ve yardım etmeden ibarettir.

Yeni yasaya göre suça iştirakte, faillik veya şeriklik söz konusu olabilmektedir. Şeriklik ise, azmettiren ve yardım eden olarak ikiye ayrılmaktadır. Böylece 765 sayılı Yasada asli manevi fail sayılan azmettiren, 5237 sayılı Yasada fail olarak kabul edilmeyip, şerikler arasında sayılmıştır. Bir suçun işlenmesinde asıl sorumluluk faillere ait olup, şerikler ise 40. maddede yer alan **bağlılık kuralı** gereğince sorumlu tutulabilmektedirler.

Yasa koyucunun 37. maddenin 1. fıkrasındaki “*suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur*” ifadesiyle faillik kavramının kapsamını oldukça geniş tuttuğunu söyleyebiliriz. Anılan madde uyarınca müşterek faillikten söz edilebilmesi için birden fazla suç ortağı tarafından, birlikte suç işleme kararına bağlı olarak suçun icrai hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla, filin icrası üzerinde müşterek hakimiyet kurulması gerekmektedir. Suçun işlenmesini sağlayan hareket üzerinde hakimiyet kuran herkes fail sayılabilecektir. Hareket üzerinde hakimiyet kurmak, birlikte irtikap etme şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi, zımnî veya açık bir iş bölümüne dayalı olarak hareketi birlikte gerçekleştirmeyi de kapsayabilir. Öyle ki, bu anlamda suçu sonuçlayan hareketi yapmayan, fakat bir başkasının bu hareketi yapması için gerekli ortamı hazırlayanlardan her birisi de fail sayılabilecektir.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun aşağıdaki kararlarında da yeni TCK’nın **suça iştirake** ilişkin hükümleri hakkında genel açıklamalara yer verilmiştir:

CGK, **3.7.2012**, E. 2012/6-134, K. 2012/270; CGK, **6.3.2012**, E. 2011/1-345, K. 2012/73; CGK, **10.5.2011**, E. 2011/5-83, K. 2011/84; CGK, **16.2.2010**, 2009/1-251, 2010/25; CGK, **13.10.2009**, E. 2009/1-194, K. 2009/235; CGK, **20.1.2009**, E. 2008/1-232, K. 2009/2.

Ancak belirtmemiz gerekir ki, Ceza Genel Kurulu’nun **13.10.2009** tarihli ve E. 2009/1-194, K. 2009/235 sayılı Kararında bu genel açıklamalara ek olarak şu değerlendirmede bulunulmuştur:

“Buradan çıkartabileceğimiz netice, suçun işlenmesi sırasında mağdura yönelik olarak yapılacak hareketlerin çoğu kez yardım etme olarak değil, faillik olarak değerlendirileceği yönünde olacaktır. Ancak, bu ifadeden yardım etmenin sadece suçun işlenmesinden önce veya sonra mümkün olabileceği sonucunun da çıkartılmaması gerekir. Zira, yardım etme her aşamada mümkün olabilecek ise de daha çok *suçun işlenmesinden önceki ve sonraki hareketler* yardım etme olarak değerlendirilebilecektir.”

Bu izahta **suçun işlenmesinden sonraki hareketlerle** de suça yardım eden sıfatıyla iştirak edilebileceği şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuştur. Bu değerlendirmenin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Suç tamamlandıktan sonra artık tamamlanmış olan bir suça iştiraktan söz edilemez. **İştirak ancak icrası devam eden bir suç bakımından söz konusu olabilir.** Bu itibarla yardım eden sıfatıyla suça iştirak, kural olarak suça ilişkin icra hareketleri başlamadan önce, yani hazırlık hareketleri evresinde mümkündür. Buna karşılık, suçun icrası aşamasında yardım eden sıfatıyla iştirak, ancak özgü suçlar bakımından söz konusu olabilir. Özel faillik vasfı taşımayan kişi bu vasfı taşıyan kişinin işlemekte olduğu özgü suçun icrası aşamasında bu suça iştirak ettiğinde, bu suçtan dolayı ancak yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulabilir.

Suçun işlenmesinden sonraki hareketler, suça iştirake ilişkin hükümler çerçevesinde değil; “*Suç eşyasını satın alınması veya kabul edilmesi*” (TCK, m. 165), “*Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme*” (TCK, m. 281), “*Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama*” (TCK, m. 282) “*Suçluyu kayırma*” (TCK, m. 283), “*Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme*” (TCK, m. 284) gibi ayrı suçlar oluşturduğu için cezalandırılırlar. Bu nedenle, Ceza Genel Kurulu’nun söz konusu kararında yer alan açıklamaların düzeltilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Nitekim CGK’nın yukarıda zikrettiğimiz daha sonraki kararlarında bu değerlendirilmeden sarfınazar edilmiştir.

C. Müşterek Faillik

765 s. TCK'nın 64. maddesinin 1. fıkrasında “*fiili irtikâp etmek*” ve “*doğrudan doğruya beraber işlemek*” ifadelerine yer verilmişti.

Bunlardan “*fiili irtikâp etmek*”, ancak suçun kanunî tarifine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, yani, icra hareketlerinin yapılması halinde söz konusu ol-maktaydı¹⁰⁶⁷. “*Fiili doğrudan doğruya beraber işle*”yen şahısla fiili icra eden ara-sında bir işbirliği söz konusuydu ve onun fiiliyle suçu meydana getiren icra ha-reketinin aynı zamanda (hemzaman) olması gerekmektedir^{1068, 1069}.

Yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısında ise, “*fiili irtikâb edenler*” ve “*doğru-dan doğruya beraber işlemiş olanlar*” ayrımı terk edilmişti. Bu ayrımın yerine genel olarak “*fiili birlikte icra edenler*” ifadesi kullanılmıştı (m. 40, f. 1)¹⁰⁷⁰.

Yeni TCK’nın 37. maddesinin birinci fıkrasına göre, “*suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.*”

Bu hükümde *müşterek faillik* düzenlenmiştir. Nitekim, madde gerekçesinde, “*suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, bu kişilerin her biri **müşterek fail** olarak sorumlu tutulacaklardır.*” denilmektedir¹⁰⁷¹.

Bu itibarla, yeni TCK’nın sisteminde “*fiili birlikte gerçekleştiren kişiler*”, müş-terek failler olarak ifade edilmiştir.

Müşterek failliğin kapsam ve koşulları aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

1) Suçun İşleniş Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurulması

Kanunî tarife uygun haksızlığı kişi yalnız başına gerçekleştirebilir. Bu durumda **doğrudan** veya **müstakil faillikten** bahsetmekteyiz.

Birlikte suç işleme kararına bağlı olarak, suçun icraî hareketlerinin birlikte ger-çekleştirilmesi ve dolayısıyla, haksızlık teşkil eden fiilin icrası üzerinde müşterek hakimiyet kurulması halinde söz konusu olan iştirak şekline **müşterek faillik**

¹⁰⁶⁷ DÖNMEZER/ERMAN II, no.1287; ÖNDER, Genel Hükümler II, 503.

¹⁰⁶⁸ DÖNMEZER/ERMAN II, no.1288; ÖNDER, Genel Hükümler II, 504.

¹⁰⁶⁹ Bir adam kaldırma suçunda “sanık A, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle müşterek haneyi terkederek babasının evine giden ... karısı S’yi diğer sanık K’nın yardımıyla babasının evinden cebir ve şiddet kullanmak suretiyle alarak kendi annesinin evine götürmüştür”. Bu olayda Yargıtay, sanık K’nın “suça doğrudan katıldığı”na karar vermiştir (5. CD, 20.1.1982, 1/66 [YKD 1982, 871]).

Ayrıca Yargıtay, müteaddit kararlarında ırza tecavüz suçunun işleniş sırasında bizzat cinsel ilişkide bulunmamakla beraber, diğer suç ortağının bu ilişkiyi gerçekleştirmesini temin amacıyla mağdurenin elini, kafasını vs. tutan şahsı “aslı şerik” veya “doğrudan doğruya beraber işleyen” olarak nitelendirmektedir (5. CD. 5.4.1978, 1142/1136 [YKD 1979, sh. 291]; 5. CD. 18.4.1979, 1020/1020 [Çağlayan I, sh. 786]; 5. CD. 1.10.1980, 2671/3102 [YKD 1981, sh. 373]).

¹⁰⁷⁰ ’97 Öntasarısı, m. 38, f. 1; ’89 Öntasarısı, m. 38, f. 1.

¹⁰⁷¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 444 vd.

denmektedir. Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurulduğu için, her bir suç ortağı fail statüsündedir.

Müşterek faillik, suçun icraî hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesidir. Müşterek faillik, birlikte suç işleme kararına bağlı olarak, suçun icrasına ilişkin işbölümü esasına dayalı ortak katılım sonucunda bunun icrası üzerinde kurulan müşterek hakimiyeti gerekli kılmaktadır. Her müşterek fail, suçun icrasına ilişkin müessir, fonksiyonel bir katkıda bulunmaktadır. Öyle ki; bu katkı, suç planının başarıya ulaşması açısından önem arz etmektedir ve bu itibarla da, fiil üzerinde müşterek hakimiyetin esasını teşkil etmektedir.

Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurulduğu için, her bir suç ortağı fail statüsündedir. İşlenen haksızlıkla doğrudan temas halinde olan müşterek faillerin bu haksızlıktan sorumlu tutulabilmeleri için bağıllık kuralına gerek yoktur. Başka bir ifadeyle; müşterek faillikte sorumluluğun esası, bağıllık kuralına dayanmamaktadır. Müşterek failler, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, işbölümü esasına dayanan müşterek katılım dolayısıyla, işlenen haksızlıktan doğrudan doğruya ve karşılıklı olarak sorumlu tutulacaklardır¹⁰⁷².

Müşterek failler, suçun işlenişine bulundukları iştirak katkılarıyla suçun kanunî tarifinde yer alan objektif, maddi unsurların hepsini yalnız başına gerçekleştirmek zorunda değildirler; fakat, aralarındaki işbölümü gereğince, bu maddi unsurlardan bir kısmını gerçekleştirmekle de fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurabilirler. Meselâ bir banka soygunu sırasında suç ortaklarından biri silahıyla bankadakileri etkisiz hale getirirken, diğeri kasadaki paraları alır. Bu gibi olayda her iki suç ortağının suçun işlenişine bulundukları katkılar, söz konusu suçun icrası açısından birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, her iki suç ortağı, suçun icrası üzerinde müşterek bir hakimiyet kurmaktadır^{1073,1074,1075}.

¹⁰⁷² ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 261 vd.

¹⁰⁷³ ROXIN, Täterschaft, 278; aynı yazar, LK(10), § 25, kn. 108.

¹⁰⁷⁴ Mülga 765 s. TCK'nın yürürlükte olduğu dönemde Yargıtay, benzeri olaylarda bütün müşterek faillerin cezalarında bu Kanunun 463. maddesine istinaden indirim yapmakta idi. Bu yöndeki kararlar için bkz. Kitabımızın 7. basısı sh. 463, dn. 911.

Yargıtay'ın bu görüşü doğru değildi. Bu kararlara konu teşkil eden bütün olaylarda suçun işlenişine iştirak eden suç ortakları işlenen fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurmuşlardır. Birlikte suç işleme kararına istinaden hareket eden ve suçun icrasını müştereken gerçekleştiren bu suç ortaklarının cezasında mülga 765 s. TCK'nın 463. maddesine göre indirim yapılması, bu suç ortakları açısından haksız bir imtiyaz teşkil etmekteydi. Mağdur üzerinde etkili olan bu iştirak katkılarından "hangisinin ölümüne sebebiyet verdiği", "hangisinin öldürücü darbeyi teşkil ettiği" şeklindeki sun'î gerekçelerle müşterek faillerin cezasında indirim yapılması hukuk vicdanıyla bağdaşır bir durum değildi. Böyle bir mantık, iştirake ilişkin meseleleri illiyet bağı esasına göre izaha gayret eden 19. yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir kalıntısı mahiyeti taşımakta idi.

¹⁰⁷⁵ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 9.6.2009 tarihli ve E. 2009/1-10, K. 2009/149 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; aralarında ihtilaf bulunan V ile A, karşılıklı olarak telefonla birbirlerini aramak suretiyle, hakaret ve tehdit ederler. İD olaya muttali olur. İD'nun sevk ve ida-

re ettiği araca önce V ve İK biner; bilahare çağırdıkları A'yı da araca alırlar. Aracın ön koltuğunda İD'nin yanında V, arka koltukta ise, A ile İK oturur. Otomobil içinde V ile A arasında tartışma başlar. Tartışmaya İK da katılır. Bilahare İK ile A arasında arka koltukta boğuşma başlar. Bu boğuşma sırasında İK ve A'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kesici ve delici alet yaralanmaları meydana gelir. Keza bu boğuşma sırasında ön koltukta oturan V, tabancası ile "A'nın bulunduğu yöne" ateş eder. Aracı kullanmaya devam eden İD, "kendi aracında meydana gelen olayı önlemek yönünde de herhangi bir girişimde bulunmaz". İD, olaydan sonra aracı durdurur ve aldığı yaraların etkisiyle bilahare ölen A, yaralı vaziyette araçtan inerek kaçar. Bunun üzerine İD, V ve İK'yı aracıyla kendi işyerine getirir. V silahı İD'ye verir. İD, silahı saklar. Daha sonra, İD, olayın meydana geldiği aracı yıkatır.

Ceza Genel Kurulu, söz konusu kararında, yeni TCK'nın suça iştirake ilişkin hükümleri hakkından özet bilgilere yer verdikten sonra, A'ya karşı V, İK ve İD tarafından iştirak halinde işlenen kasten öldürme suçundan dolayı İD'nin müsterek fail olarak değil, *yardım eden* sıfatıyla, yani şerik olarak sorumlu tutulması gerektiği yönünde içtihadta bulunmuştur.

Mülga 765 s. TCK'nın yürürlükte olduğu dönemde egemen olan düşüncenin etkisiyle yapılan bu değerlendirme yeni TCK'nın suça iştirake ilişkin hükümleri ile uyumsuzdur. Somut olayda İD, diğer suç ortakları V ve İK ile birlikte A'nın yaralanması ve bilahare ölmesi sonucunu doğuran fiillerin işlenişinde müsterek hakimiyet tesis etmiştir ve bu nedenle, **müsterek fail** olarak sorumlu tutulması gerekirdi. Esas Mahkemesi olan Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin direnme kararı ve gerekçesinde yer verdiği açıklamalar doğru olmasına rağmen, CGK, benzer olaylarda verdiği diğer kararlarla uyum arz etmediği halde, somut olayda İD'nin yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Nitekim, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20.1.2009 tarihli ve E. 2008/1-232, K. 2009/2 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; H, satın almayı çok istemesine rağmen, parasal konularda ev sahibi ile anlaşamadığı için evi satın alamaz. Emlak komisyoncusu K, satmak için başka müşteriler arayarak, evi bulduğu kişilere gösterir. H, bu duruma kızar ve K'ya hakaret eder. Bu nedenle aralarında çıkan kavgaya H'nin oğulları M ve E de katılır. Kavgası sırasında H, K'nın boynunu koltuğunun altına sıkıştırır ve bu vaziyette iken M, mutfak bıçağı ile K'ya altı darbe vurur. K ölür.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararında K'nın öldürülmesinden dolayı H'nin, yardım eden sıfatıyla mı yoksa fail olarak mı sorumlu tutulması gerektiği tartışılmış ve bu tartışma sonucunda **fail** olarak sorumlu tutulması gerektiği içtihadında bulunulmuştur.

Bu içtihadta bulunulurken Kararda şu değerlendirmelere yer verilmiştir:

"Yasa koyucunun 37. maddenin 1. fıkrasındaki "suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur" ifadesiyle **faillik kavramının kapsamını oldukça geniş tuttuğunu** söyleyebiliriz. Bu durumda, **suçun işlenmesini sağlayan hareket üzerinde hakimiyet kuran herkes** fail sayılabilecektir. Hareket üzerinde hakimiyet kurmak, birlikte irtikap etme şeklinde gerçekleşebileceği gibi, zımni veya açık bir iş bölümüne dayalı olarak hareketi birlikte gerçekleştirmeyi de kapsayabilir. Öyle ki, bu anlamda **suçu sonuçlayan hareketi yapmayan, fakat bir başkasının bu hareketi yapması için gerekli ortamı hazırlayanlardan her birisi de fail sayılabilecektir**. Buradan çıkartabileceğimiz netice, **suçun işlenmesi sırasında mağdura yönelik olarak yapılacak hareketlerin çoğu kez yardım etme olarak değil, faillik olarak değerlendirileceği** yönünde olacaktır." Ayrıca bkz. CGK, 2.4.2013, E. 2012/10-1323, K. 2013/117; CGK, 5.4.2016, E. 2015/6-681, K. 2016/179.

Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yeni bir kararında bu açıklamalarla telifi kabil olmayan içtihadta bulunmuştur:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 25.4.2017 tarihli ve E. 2014/14-635, K. 2017/250 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda henüz 11 yaşını tamamlamamış olan C, ailesinden habersiz olarak, B tarafından zorla evden alınarak A'nın evine götürülür. B, evde alıkoyduğu C'ye karşı birkaç defa cinsel istismar girişiminde bulunur ise de, ev ortamının müsait olmaması sebebiyle

Müşterek hakimiyetin kurulup kurulmadığının tayininde suç ortaklarının suçun icrasındaki rol dağılımları ve suçun işlenişine bulunulan katkının arzettiği önem, zaruret, gözönünde bulundurulacaktır. Öyle ki, fiilin icrası veya akim kalması müşterek faillerden her birinin elinde bulunmaktadır¹⁰⁷⁶. Müşterek failin suçun icrasına bulunduğu katkının arzettiği bu zaruret nedeniyle; burada, *fonksiyonel, müessir fiil hakimiyeti*, bir başka ifadeyle, icraî faaliyette bulunmayı gerekli kılan fiil hakimiyeti kavramı kullanılmaktadır¹⁰⁷⁷.

Buna göre, suçun icrasına bulunulan katkı, suçun başarıyla işlenmesi açısından zorunluluk arz ediyorsa, bu suç ortağı müşterek faildir. Öyle ki, suçun işlenişine bulunulan her bir müşterek katkı, fiilin başarıyla tamamlanması açısından gereklilik arzettiği gibi; bu müşterek katkılardan herhangi birinden vazgeçilmesi, fiili gerçekleşmeme, akim kalma tehlikesine maruz bırakır¹⁰⁷⁸.

le bu girişimlerinde başarılı olamaz. C, bir hafta süreyle A'nın evinde tutulduktan sonra, B tarafından bu defa kendi evine götürülür. C, birkaç gün de bu evde tutulduktan sonra, B'nin anesi tarafından ailesine teslim edilir.

İlk Derece Mahkemesi bu olayda B'yi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkum etmiş; buna karşılık, A hakkında ise **beraat** hükmü kurmuştur (Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2.10.2013, 332-420).

Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise, A hakkında B'nin C'ye karşı işlediği kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna **yardım eden** sıfatıyla mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken, beraat kararı verilmesini hukuka aykırı bularak, İlk Derece Mahkemesinin kararını bozmuştur (27.3.2014, 465-4129).

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14. Ceza Dairesinin bu bozma kararına aşağıdaki gerekçe ile itiraz etmiştir (2.7.2014, 377321).

“... Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bünyesinde teselsülü de kapsamaktadır. Bu itibarla sanık A'nın mağdurenin bir hafta süreyle bir yerde kalma veya bir yere gitme hürriyetinin engellenmesinde suçun işlenmesindeki rolü, sağladığı katkının önemi, **fiil üzerinde ortak hakimiyet kurması** ve suç işleme kararındaki birlik nazara alındığında TCK'nın 37. maddesi anlamında **fail** olarak sorumlu tutulması gerekmektedir.”

Yargıtay Ceza Genel kurulu ise, aşağıdaki gerekçe ile, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE karar vermiştir:

“Sanık B'nin, 11 yaşının içinde bulunan mağdureyi ... arkadaşı olan sanık A'nın ailesiyle yaşadığı eve götürüp burada mağdure ile birlikte bir hafta kaldığı olayda; mağdurenin aşamalarındaki beyanları, **sanık A'nın savunmaları** ve tüm dosya kapsamından, sanık **B ile birlikte suç işleme kararı bulunmadığı** anlaşılan **sanık A'nın, sanık B'nin fiili üzerinde ortak hakimiyet kurduğunu gösterir herhangi bir davranışının da olmaması** karşısında, sanık A'nın kalacak yer sağlamak suretiyle sanık B'nin işlediği kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun icrasını kolaylaştırdığı ve buna bağlı olarak TCK'nın 39/2-c maddesi kapsamında suça **yardım eden** olarak iştirak ettiği kabul edilmelidir.”

¹⁰⁷⁶ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 294/295; ROXIN, Täterschaft, 280.

¹⁰⁷⁷ Kavramı ilk ihdas eden Roxin olmuştur. Ancak, bilahare doktrinde büyük ölçüde kabul görmüştür: JESCHECK, Lb., 616; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 823; SAMSON, SK(4), § 25, kn. 43; RUDOLPHI, Bockelmann-F., 374; BLOY, 376; fonksiyonel fiil hakimiyeti kavramını eleştirmekle birlikte, muhtevada hemfikir olan, HERZBERG, Täterschaft, 61.

¹⁰⁷⁸ Yargıtay, icrası üzerinde hâkimiyet kurulabilen suçlarda fail/şerik ayırımını yaparken, suçun işlenişine bulunulan katkının suçun genel işlenişine açısından arzettiği önemi, ağırlığı esas almaktadır.

Ancak, bütün bu izahlardan, suçun işlenişine bulunulan katkının meydana gelen netice açısından illiyet bağı itibarıyla zorunluluk arzedip etmediği hususunun müşterek failliğin tayininde esas alındığı şeklinde bir sonuç çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde, fiil üzerindeki müessir, fonksiyonel hakimiyet ile, suçun işlenişine bulunulan iştirak katkısının meydana gelen netice açısından zorunluluk arzedip etmediğine göre suç ortaklarının iştirak statülerini belirleyen "*zorunluluk teorisi*"¹⁰⁷⁹ birbirine karıştırılmış olur. Ex post bir araştırmayla suçun işlenişine bulunulan katkının, meydana gelen netice açısından illiyet bağı itibarıyla zorunluluk arzedip etmediğini reel olarak belirlemeye çalışmak isabetli değildir. Çünkü, böyle bir "tespit", farazî bir teşhisten öteye geçemez. Halbuki suçun işlenişine bulunulan bütün iştirak katkıları, illiyet bağlantısı itibarıyla gerçekte meydana gelen netice açısından zorunluluk arzederler.

Burada bizi isabetli sonuca ulaştıracak olan kıtas, yine sağlıklı bir değerlendirmedir. Olayın somut oluşum şartları dikkate alınmak suretiyle yapılacak söz konusu değerlendirme, suçun işlenişine bulunulan katkının icra ettiği fonksiyon-

Hırsızlık suçunda "sanıklardan Y ve M mağdurun banyo penceresi yanına birlikte gelmişler ve pencereyi tornavida ile açıp içeri girdikten sonra mağdura ait ... eşyaları bir çantaya doldurarak yukarı katta bekleyen sanık E'nin sarkıttığı ipe çantayı bağlamışlar, sanık E çantayı yukarı çekmiş ve diğer sanıklar da aynı yolla yukarı çıkmışlardır. Sanıklar böylece hırsızlık suçunu müştereken gerçekleştirmişlerdir. ... Sanıklar anlaşarak birlikte fiili icraya başlamışlar ve birlikte gerçekleştirmişlerdir. Sanık E'nin fiili ... aslı iştiraktır.": CGK. 26.4.1982, 6-114/171 (YKD 1982, sh. 998).

Yargıtay, kaçırma ve alıkoyma suçunda "sanık C'nin diğer sanıklarla müdahilin kaçırılması hususunda önceden karar birliğine vararak olay mahalline geldiği ve müdahilin zorla kaçırıldığı esnada onun babasını tutmaktan ibaret fiillerinin kaçırma suçunun icraî hareketlerine dahil bulunduğu" sonucuna varmıştır (5. CD. 4.11.1980, 3286/3575 [YKD 1981, sh. 509]; aynı şekilde 5. CD. 21.12.1982, 4706/4771 [Çağlayan I, sh. 785]).

Ancak Ceza Genel Kurulu, bir kararında müessir fiil suçunun mağduru "olay sırasında sanık T'nin kendisine yumrukla vurduğunu, diğer sanık Ş'nin ise kendisine vurmadığını, sadece tuttuğunu bildirmesine ... göre," tutan şahsın şerik olarak sorumlu tutulması gerektiği sonucuna varmıştır. "Zira ... Ş'nin mağduru sadece tuttuğu ... sanık T'nin yumrukla vurmasından önce olduğu anlaşılmamaktadır." (CGK. 26.1.1987, 2-339-3 [Uygun/Savaş/Mollamahmutoğlu, Ceza Genel Kurulu Kararları, 1987, sh. 29]). Keza Genel Kurul, "sanık R'nin M'yi bıçakla yaralaması olayında, mağduru tutmak suretiyle ona yardım ve müzaharette bulun"an diğer suç ortağını yine şerik olarak sorumlu tutmuştur (CGK. 24.11.1986, 136/528 [YKD 1987, 1545]; ayrıca 2. CD. 15.9.1981 [Çağlayan I, 806]). Bu son iki kararda Yargıtay, fail/şerik ayırımında sıkı bir şekilcilğe eğilim göstermektedir. Buna göre, sadece hareketi kanunî tipe uygunluk arzeden suç ortağı/ortakları fail olabilmektedir.

1. Ceza Dairesi bir kararında, "aslı fail sanık Mustafa'nın ... maktül Bekir'e av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü, aslı failin yanında bulunan diğer sanıklar Hasan ve Behçet'in de tabancalarla maktule ateş ettikleri ... (halde,) aslı fail av tüfeği ile ateş ederek mağduru öldürdüğü sırada onun yanında bulunmak, fiiline engel olmamak, bilâkis kendileri de tabancalarla ateş etmek suretiyle diğer sanıklar Hasan ve Behçet'in" şerik olarak sorumluluğu cihetine gitmektedir (1. CD. 20.9.1985, 2355/3201 [YKD 1986, 285 vd.]; ayrıca 1. CD. 2.4.1987, 1063/1055 [YKD 1987, 1820 vd.]).

¹⁰⁷⁹ "Notwendigkeitstheorie".

nun objektif anlamını belirlememizi sağlayacaktır. Sonuç olarak diyebiliriz ki; suçun işlenişine bulunulan katkının meydana gelen haksızlığın işlenişi açısından arzettiği önemden, zarureten bahsederken, "bu katkıda bulunulmasaydı suç hiç bir surette işlenmeyecekti" şeklinde bir farazî fikir yürütümüne müracaat etmemekteyiz. Zira, yukarıda da belirttiğimiz gibi, böyle bir ex post tespit mümkün değildir¹⁰⁸⁰.

Suçun işlenişi üzerinde müşterek hakimiyet kurabilmek için, suç ortağının fiilin işlenişine doğrudan müdahalede bulunması gerekmez. Sözgelimi suç işlemek için oluşturulmuş teşekküllerde, örgütün lideri durumundaki suç ortağının, işlenen suçlara doğrudan müdahalede bulunması zorunlu değildir. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda ancak emir ve kumandayı elinde bulunduran durumundaki suç ortağının talimatları, planları sayesinde suçun icrası mümkün olmaktadır. Aksi takdirde suçun işlenmesi akim kalabileceği gibi, teşekkülün varlığının bir anlamı da olmaz¹⁰⁸¹.

Müşterek faillik için olay mahallinde bizzat bulunmak zorunlu değildir. Uzak-tan da olsa, meselâ telsiz vs. ile fiilin işlenişini yönlendirmek suretiyle müşterek fail olarak suçun icrasına iştirak mümkündür. Suç vakiasının planlanmasına ve tertiplenmesine iştirak eden suç ortağı, şayet bilahare fiilin icrasına iştirak etmemekteyse, fiilin icrası üzerinde fonksiyonel, müessir bir hakimiyet kurmuyorsa, müşterek fail olarak değil, aşağıda açıklayacağımız gibi, şerik (yardım eden) olarak sorumlu tutulacaktır.

Suçun icrasına ilişkin esaslı, ayrıntılı plan hazırlamak, müşterek fail olarak sorumluluk için esas alınamaz. Zira, suç planını hazırlayarak bir başkasını suç işlemeye azmettirme halinde, kişinin müşterek fail olarak değil; azmettiren olarak sorumluluğu cihetine gidilmektedir¹⁰⁸².

¹⁰⁸⁰ ROXIN Täterschaft, 283. Özellikle Müşterek Hukuk dönemi Ceza Hukukçularınca kabul edilen "zorunlu fer'i iştirak" müessesesine göre, mahiyet itibarıyla yardımda bulunma özelliği arzeden bir iştirak katkısı şayet suçun işlenmesi açısından zaruret arz ediyorsa, ilgili suç ortağı "fail" olarak sorumlu tutulmaktadır. Halbuki böyle bir durumda kişi, her ne kadar suçun işlenişini ilk defa mümkün kılmaktaysa da, fiilin işlenişinde henüz hakimiyet kurmuş değildir. Şöyle bir örnekle mesele daha iyi anlaşılacaktır: Parası olmayan bir antika eşya hırsızına müzeye giriş için gerekli parayı tedarik eden kişi, bu parayı vermekle hırsızlık suçunun işlenmesini mümkün kılmıştır. Başka bir ifadeyle, kişi bu parayı vermeseydi hırsızlık suçu işlenmeyecekti. "Zorunlu fer'i iştirak" düşüncesine göre, suçun icraî hareketlerine hiçbir katkısı olmayan ve sadece hırsızın müzeye girişi için gerekli parayı tedarik eden kişiyi "(müşterek) fail" olarak sorumlu tutmak gerekecektir. Böyle bir düşünüş, fiil hakimiyeti kıstasıyla bağdaştırılamaz. Bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 123 vd.

¹⁰⁸¹ ROXIN, Täterschaft, 280; ayrıca bkz. aşağıda § 6, II, 6.

¹⁰⁸² ROXIN, LK(10), § 25, kn. 129; aynı şekilde HERZBERG, Täterschaft, § 5 II 2a; SAMSON, SK(4), § 25, kn. 47. Nitekim, bizde Askerî Yargıtay, iştirak statülerinin belirlenmesinde bir suç ortağının suçun işlenişine bulunduğu katkıyla suçun icrasında "mühim bir rol oynama"sını ölçü olarak almaktadır. Ask. Yarg. DKK. 26.3.1987, 61/58 (Ask. YKD 6[1990], sh. 17 vd. [19]). Ancak, Yargıtay, öldürülenin kaçmasını engellemek suretiyle öldürme suçunun işleni-

Buna karşılık, suçun icrası açısından müstakil bir fonksiyonu olmayan bir katkıda bulunulması halinde, müşterek hakimiyetten bahsedilemez. Müşterek faillik için, suçun icrası aşamasında bulunulsa bile, bir iştirak katkısı, suçun işlenişi açısından bir önemi haiz olmalıdır; başka bir ifadeyle, suç ortakları arasındaki işbölümü gereğince suçun icrası üzerinde müessir, fonksiyonel bir hakimiyet kurulmasını sağlayacak ağırlıkta olmalıdır. Bu itibarla, örneğin sahte evrak tanzim eden kişiye mürekkep tedarik etmek, bu suçun işlenişinde müşterek fail olmayı gerektirmez¹⁰⁸³.

Müşterek faillik, her zaman, yukarıdaki banka soygunu örneğinde olduğu gibi, suç ortaklarının iştirak katkılarının karşılıklı olarak birbirlerini tamamladığı klasik şekliyle karşımıza çıkmamaktadır. Bazı hallerde, müşterek faillerden her biri suçun kanunî tarifindeki bütün unsurları tek başına gerçekleştirmeye gayret etmek üzere, bir müşterek anlaşmaya varılır. Böyle bir durumda müşterek hareket etmenin amacı, fiilin akim kalma ihtimalini mümkün olduğunca aza indirmektir. Fakat, bu demek değildir ki, böyle bir ihtimalde her bir suç ortağının suçun işlenişine bulunduğu katkı bizzatî önemsizdir. Aksine, suçun icraî hareketlerini gerçekleştirecek suç ortağı sayısının artırılması suretiyle, suç planının başarıya ulaşması ihtimalinin mümkün olduğunca artırılması, sağlama alınması amaçlanmaktadır¹⁰⁸⁴. Meselâ bir kasten öldürme suçunu işlemek için aralarında anlaşmış olan yirmi kişi, amacın gerçekleşme ihtimalini daha da yükseltmek için, aynı anda mağdurun üzerine ateş ederler. Ateşlenen mermilerden bir kısmı mağdura isabet eder, bir kısmı ise etmez¹⁰⁸⁵.

Olay ex ante bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda, her bir suç ortağının suçun işlenişine bulundukları katkıların icra ettiği fonksiyonun, suç planının başarıyla sonuçlanması ihtimalini artırmak olduğu görülür. Bu durumda her bir suç ortağının suçun işlenişine bulunduğu katkının eşdeğerde olduğu anlaşılır. Zaten bu nokta, müşterek faillik açısından aranan hususlardan birisidir. Neticenin gerçekleşmesi, iştirak statülerinin belirlenmesinde önemi haiz değildir. Örnek olayımızda müteaddit suç ortağı suçun kanunî tarifindeki fiili bizzat gerçekleştirmeyi kararlaştırmakla ve müşterek hareket etmekle beraber, mermilerden bir kısmı mağdura isabet etmemiş olabilir. Böyle bir durumda mesele, bütün suç ortaklarının, şüpheden sanık yararlanır *-in dubio pro reo-* prensibi gereğince adam öldürmeye teşebbüsten dolayı mı, yoksa tamamlanmış adam öldürme suçundan dolayı mı sorumlu tutulmaları gerektiğidir.

şine iştirak eden şahsın "müzaheret ve muavenetle suçun icrasını kolaylaştıran", yani yardımcı bulunan olarak sorumlu tutulması gerektiği kanaatindedir: 1. CD. 27.6.1990, 1690/1988 (YKD Eylül 1990, sh. 1384 vd.).

¹⁰⁸³ ROXIN, Täterschaft, 284; aynı yazar, LK(10), § 25, kn 108, 131, 132; JESCHECK, Lb., 616; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 824; SAMSON, SK(4), § 25, kn. 47; BLOY, 369/370; HERZBERG, Täterschaft, 69.

¹⁰⁸⁴ BLOY, 372/373.

¹⁰⁸⁵ HERZBERG, Täterschaft, 56.

Hemen ifade etmek gerekir ki, örnek olayımızda bütün suç ortakları müşterek suç işleme kararına istinaden hareket etmektedirler ve suçun icraî hareketlerini müştereken gerçekleştirmektedirler. Bu yirmi suç ortağının ateşlediği mermilerden sadece bir tanesinin hedefe isabet etmesi halinde dahi, bir tamamlanmış kasten öldürme suçunun mevcut olduğunu, fakat, bu suçun faili, bir tek kişi olmayıp, yirmi kişiden müteşekkil bir grup olduğunu kabul etmek gerekecektir¹⁰⁸⁶. Nasıl ki bir kişi mağduru öldürmek için yirmi el ateş edip de bunlardan sadece bir tanesinin hedefe isabet etmesi halinde, (hukuki anlamda) hareket birliğinin mevcudiyeti nedeniyle, bu kişiyi tamamlanmış bir kasten öldürme suçundan ve on dokuz defa kasten öldürme suçuna teşebbüsten dolayı sorumlu tutmuyorsak; olayımızda da aynı düşünceden hareketle bütün suç ortaklarını bir tek tamamlanmış kasten öldürme suçundan dolayı sorumlu tutmak gerekecektir^{1087,1088}.

Her bir suç ortağının ateşlediği merminin hedefe isabet etme ihtimalinin farklılık arzettiği durumlarda dahi, müşterek failiğin varlığını kabul etmek gerekecektir. Hedefe isabet etme ihtimali en az olan mermiyi ateşleyen suç ortağını bu sebeple şerik (yardım eden) olarak sorumlu tutamayız. Zira, uzaklık ve saire gibi somut olayın şartlarından kaynaklanan sebeplerle hedefe isabet etme ihtimalinin az olduğu suç ortağı da, silahını ateşlemekle korunan hukuki değere doğrudan tecavüz etmiştir. Bir başka ifadeyle, bu suç ortağını, bir başkasının gerçekleştirdiği haksızlığa bulunduğu katkıdan dolayı değil; haksızlıkla doğrudan temas halinde, ilişki içinde olduğu için müşterek fail olarak sorumlu tutmaktayız¹⁰⁸⁹.

Ancak işaret etmek gerekir ki; ceza hukuku doktrin ve uygulamamızda bu tür olaylarda müşterek faillerin kasten öldürme veya kasten müessir fiil (kasten yaralama) suçuna göre belirlenen cezasının 765 s. TCK'nın 463. maddesine göre indirilmesi gerektiği konusunda fikir birliği mevcuttur¹⁰⁹⁰. Çünkü, bu anlayışa

¹⁰⁸⁶ BLOY, 374.

¹⁰⁸⁷ Nitekim HERZBERG, Täterschaft, 57, 60; JESCHECK, Lb., 255; ROXIN, Täterschaft (4. bası), 619.

¹⁰⁸⁸ Bu itibarla, Türk Ceza Kanununun bu gibi ihtimallerde, yani mağdura isabet eden merminin hangi müşterek failin silahından çıktığının anlaşılamadığı durumlarda, müşterek faillerin cezasında belli oranda indirim yapılmasını öngören 463. maddesi hükmünün adil bir çözüm getirdiğini iddia etmek mümkün değildir (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 293 vd.).

Ayrıca, additif (cem'i) müşterek failik halinde bütün müşterek faillerin teşebbüs derecesinde kalmış suçtan dolayı sorumluluğu cihetine gidilmesini savunan fikir de (SCHILLING, Georg: Der Verbrechensversuch des Mittäters und des mittelbaren Täters, Köln/Berlin/Bonn/München, 1975, sh. 111 vd.) isabetli değildir.

¹⁰⁸⁹ BLOY, 375; aynı mealde WESSELS(19), sh. 155. Ayrıca bkz. MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 296.

¹⁰⁹⁰ Bkz. Türk doktrininde DÖNMEZER, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 13. bası, İstanbul, Mayıs 1990, no. 120 (dn. 1), 121; ÖZEK, 506; GÖLCÜKLÜ, 86; DONAY, 518 vd.; SO-YASLAN, 291 vd.

göre, 463. madde, iştirak hükümleri çerçevesinde cezalandırmanın mümkün olmadığı hallerde uygulama alanı bulacaktır.¹⁰⁹¹ 463. maddenin getirdiği düzenleme ile iştirake ilişkin hükümler tamamlanmaktadır.¹⁰⁹² 463. madde, iştirakte "ikilik" sisteminin mahzurlarını gidermektedir.¹⁰⁹³ 463. madde, özel bir iştirak düzenlemesidir.¹⁰⁹⁴

Yargıtay kararlarında aynı görüş benimsenmiştir.¹⁰⁹⁵

463. maddenin *ratio legis*ine uygun olsa bile, bu tür olaylarda müşterek faillerin cezasında söz konusu maddeye göre indirim cihetine gidilmesi, suç teorisinin ve rileriyle bağdaşmamakta ve bir kısım müşterek failler (Kanunun ifade tarzıyla, "fiili irtikâp eden"ler) lehine haksız bir imtiyaz teşkil etmektedir. Halbuki bu olaylarda birlikte suç işleme kararına istinaden bütün müşterek failler suçun icrası üzerinde müşterek bir hakimiyet kurmuşlardır; hep birlikte mağdurun üzerine ateş etmişlerdir. Müşterek failler, amaçlanan neticeye ulaşma (mağdurun yaralanması veya öldürülmesi) ihtimalini yüksek tutmak amacıyla (veya sorumluluğu müştereken taşıma gibi birtakım sübjektif mülahazalarla, saiklerle) mağdurun üzerine hep birlikte ateş etmişlerdir. Dolayısıyla, suçun icraî hareketlerini müştereken

¹⁰⁹¹ Mehaz 1889 İtalyan Ceza Kanununa ilişkin Komisyon ve Bakanlık Raporlarına istinaden DONAY, 517, 519; SOYASLAN, 283.

¹⁰⁹² ÖZEK, 505/506; GÖLCÜKLÜ, 86; SOYASLAN, 280, 283.

¹⁰⁹³ SOYASLAN, 285.

¹⁰⁹⁴ CGK. 23.11.1981, 1-214/385 (YKD 2/1982, 241 vd. [244]). Türk doktrininde Erem, 463. maddenin "müstakil bir suç" teşkil ettiği fikrindedir: Adam Öldürmek Cürümleri, 137.

¹⁰⁹⁵ «... sanıkların, attığı taşlardan birinin maktuleye isabet ettiği ve fiillerinin TCK. nun 463 ncü maddesinde gösterilen müstakil faili belli olmayacak surette, subuta erdiği anlaşılmıştır»: CGK. 26.2.1973, 1-448/177 (ÇAĞLAYAN IV, 167).

«Müşteki, sanıkların attığı taşlardan birisinin kendisine isabet ettiğini ifade etmiş olup, hangi sanığın attığı taşla yaralandığı saptanamadığına göre, tayin edilen cezaların TCK'nın 463'üncü maddesi uyarınca indirilmesi gerekir.»: 2. CD. 15.6.1983, 4212/4359 (Erdurak, 1011); aynı mealde 4. CD. 2.12.1983, 5845/6339; 1. CD. 1.2.1961, 949/3262 (EREM, Adam..., 140).

Ceza Genel Kurulu, Z, H ve A'nın müşterek suç işleme kararına istinaden birlikte müteaddit defa ateş etmeleri sonucu mağdur M'ye iki mermi isabet ettiği ve ölümüne sebebiyet verdikleri olaya ilişkin olarak şu şekilde karar vermiştir: "Olayımızda ... öldürülendeki iki öldürücü yaranın ateş eden üç sanıktan hangisi tarafından meydana getirildiği kesinlikle saptanamadığından," failler hakkında kasden adam öldürme suçuna göre tayin edilecek cezada 463. maddeye göre indirim yapılması cihetine gidilmelidir: CGK., 23.11.1981, 1-214/385 (YKD, Şubat 1982, 251). Aynı mealde CGK., 19.3.1973, 78/288 itiraz (Çağlayan IV, 165-167); CGK., 21.9.1970, 1-718/302 (Çağlayan IV, 168/169); 1. CD. 30.10.1984, 2488/4420 (Çağlayan IV, 169); 1. CD. 22.3.1983, 464/913 (Erdurak, 1012); 2. CD. 5.4.1977, 2356/2703 (Erdurak, 1021).

Keza, Yüksek Mahkeme, K, R ve M'nin her üçünün de hamili bulundukları silahlarla otomobile uzaklaşan Y ve E'yi yayılım ateşine tuttukları; ancak, hangisinin silahından çıktığı tayin edilemeyen bir merminin Fatma'ya isabet ederek, onun yaralanmasına ilişkin olayda şu şekilde karar vermiştir: "her üç sanığın maddi müstakil faili belli olmayan adam öldürmeye tam derecede teşebbüs suçunun fer'i faili telakkisi ve TCK'nın 52, 448, 62, 463. maddeleri gereğince bir defa tecziyeleri" gerekir: 1. CD. 2.10.1990, 2114/2360 (YKD Şubat 1991, 273 vd.).

gerçekleştirmişlerdir. Ancak, bazı müşterek fail(ler)in ateşlediği mermi(ler) mağdura isabet etmemiş olabilir(ler). Bütün suç ortakları, birlikte suç işleme kararıyla hareket etmekte olup, suçun icraî hareketlerini müştereken gerçekleştirmişlerdir. Bu itibarla, her ne kadar bazısının/bazılarının atışı isabet etmemişse de, bütün bu suç ortaklarını gerçekleştiren öldürme veya yaralama (müessir fiil) suçundan dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutmak gerekecektir. Hatta, mağdura isabet eden merminin/mermilerin hangi suç ortağına/ortaklarına ait silahtan çıktığı tayin edilse bile, mağdura ateş eden ve fakat isabet ettiremeyen suç ortağını da tamamlanmış kasten öldürme veya kasten yaralama suçuna iştirakten dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutmak gerekecektir¹⁰⁹⁶.

Binaenaleyh, bütün bu olaylarda, söz konusu 463. maddeye rağmen, suç ortaklarının hepsini tamamlanmış kasten öldürme veya kasten yaralama suçundan dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutmak, adalet ilkelerine daha uygun düşmektedir¹⁰⁹⁷.

Diğer bir ihtimal de şu şekilde örneklendirilebilir: A ve B, ortak düşmanları M'yi öldürmek için karara varırlar. Plana göre M'nin geçmesi muhtemel iki yoldan birinde A, diğerinde ise B pusu kurar. M, A'nın pusu kurduğu yoldan geçerken, A tarafından vurularak öldürülür¹⁰⁹⁸. Burada mesele, B'yi de bu kasten öldürme suçundan dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutabilip tutamayacağımız hususudur.

Müşterek fail olabilmek için suçun icrası aşamasında önemli bir katkıda bulunmak gerekir. Bu itibarla, bu tür olaylarda müşterek faillikten bahsedebilmek

¹⁰⁹⁶ *Gölcüklü*, bu ihtimalde mağdura isabet kaydettiremeyen müşterek failin fiilinin "teşebbüs" aşamasında kaldığı fikrindedir. Buna göre, şayet 463. madde olmasaydı "teşebbüs sanığı.. tam suç cezasıyla cezalandırılacaktı. *Gölcüklü*, bu hali "açık (bir) adaletsizlik" olarak nitelendirmektedir: GÖLCÜKLÜ, 101.

¹⁰⁹⁷ Ancak, şu örnek olayda 463. maddenin tatbik kabiliyeti olduğunu iddia etmek (SOYASLAN, 292/293), isabetsizdir. A, B ve C, D'yi dövmek üzere karara varırlar. D'yi döverlerken A, B ve C'den bir tanesi D'ye bir bıçak saplar. Bilahare bu bıçak darbesinin A, B ve C'den kimin tarafından vurulduğu anlaşılamaz. *Soyaslan*, müessir fiil suçunun bu mevsuf şekli açısından her üç suç ortağının sorumluluğunu tayin ederken, "TCK'nın 456, 457 ve 463. maddeleri"ndeki sırayı takip etmek gerektiği fikrindedir. (Aynı mealde 4. CD. 16.3.1983, 1023/1367 [Erdurak, 1012].)

Dikkat edilmelidir ki, A, B ve C, kasten müessir fiil suçunun basit şeklini (dövmek) işlemek üzere karara varmışlardır ve dolayısıyla, suçun basit şekli açısından müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır. Şayet bu bıçak darbesi ilgili suç ortağı tarafından diğer suç ortaklarının bilgisi ve iradesi dışında havale edilmişse, o zaman mesele müşterek faillikte sınırın aşılması kaidelerine göre halledilecektir.

Buna karşılık, her ne kadar önceden varılan anlaşmada belirtilmemişse de, bilahare suçun icrası sırasında müşterek faillerden birinin bıçak kullanmasına diğerleri muttali olmuş ve ses çıkarmamak suretiyle zımnen muvafakat etmişlerse, müessir fiil suçunun bu nitelikli şekli açısından anlaşma suçun icrası sırasında oluşmuş olduğu için, bu nitelikli unsur açısından da bütün suç ortakları müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır.

¹⁰⁹⁸ RUDOLPHI, Bockelmann-F., 379.

için, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, alternatif katılım da olsa, suçun icrası aşamasında etkili olacak önemli bir iştirak katkısında bulunmak gerekecektir. Buna göre, meselâ bir siyasi şahsiyeti öldürmek için binanın her bir çıkış kapısında nöbet tutan suç ortaklarından sadece bir tanesinin ateş etmesi sonucu mağdurun ölmesi halinde, diğer suç ortaklarının iştirak katkıları da suçun icrası aşamasında önemli ölçüde etkili olduğu için, bütün suç ortaklarını müşterek fail olarak sorumlu tutmak gerekecektir. Buna karşılık, meselâ yurt dışından ülkeye gelecek olan bir siyasi şahsiyeti öldürmek üzere anlaşılan suç ortakları, bu şahsiyetin ülkede gelebileceği bütün havaalanlarına dağılırlar. Ancak, X havaalanına gelmesi nedeniyle mağduru buradaki suç ortağının öldürmesi halinde, kasten öldürme suçunun faili olarak sadece bu suç ortağını sorumlu tutmak gerekecektir; diğer suç ortaklarını ise, suçun icrası aşamasında herhangi bir katkıları olmadığı için, bu suça ancak şerik (yardım eden) olarak sorumlu tutabiliriz¹⁰⁹⁹.

Suçun işlenişi sırasında gözcülük yapılması halinde, bu suç ortağının iştirak statüsünü belirlerken, somut olayın şartlarına göre bir ayırım yapılması gerekir. Buna göre, müşterek karar doğrultusunda suçun icrasına bulunulan gözcülük yapma şeklindeki katkı şayet suçun icrası açısından zorunluluk arz ediyorsa, fiilin başarıyla tamamlanması için buna gerek hissediliyorsa; bir başka ifadeyle, işbölümü esasına dayalı suçun icrasında gözcülük, müstakil bir fonksiyon icra ediyorsa, bu suç ortağı müşterek faildir. Buna karşılık, meselâ bir hırsızlık çetesine henüz yeni dahil olmuş olan bir kişiye, bu işin nasıl yapıldığını göstermek için, bir hırsızlık vakiasının işlenişi sırasında önem arzetmeyen bir noktada gözcülük görevi ifa ettirilmişse; bu gözcülük, suçun icrası açısından bağımsız bir fonksiyonu haiz olmadığı için, suçun işlenişi açısından önem arzetmediği için, ancak yardım eden sıfatıyla şerik olmayı gerektirir¹¹⁰⁰.

Bu itibarla, gözcülük yapan suç ortağının müşterek fail olarak mı, yoksa yardım eden olarak mı sorumlu tutulması gerektiği meselesinin halli, tamamen somut olayın şartlarını gözönünde bulunduracak olan hakimnin görevidir¹¹⁰¹. Fakat gözcülük faaliyetinin icrası halinde prensip olarak müşterek failliğin varlığını kabul etmek gerekecektir. Meğer ki bulunulan gözcülük faaliyeti, suçun icrası açısından gerekli olmayan, talî bir fonksiyonu haiz bulunan bir iştirak katkısı mahiyeti arzetsin¹¹⁰².

¹⁰⁹⁹ ROXIN, *Täterschaft* (4. bası), 620; aynı yazar, *Die Mittäterschaft im Strafrecht*, JA 1979, sh. 524 vd.; BLOY, 376/377. Ancak, *Maurach/Gössel/Zipf*, bu ihtimalde de müşterek failliğin mevcudiyetini kabul etmektedirler: MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 296/297.

¹¹⁰⁰ ROXIN, *Täterschaft*, 282.

¹¹⁰¹ GALLAS, *Beiträge*, 67, 104, 140; ROXIN, *Täterschaft*, 283; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 297.

¹¹⁰² ROXIN LK(10), § 25, kn. 108, 133. Ancak, *Samson*, gözcülük halinde, prensip itibarıyla yardımda bulunan olarak sorumluluk cihetine gidilmesi gerektiği fikrindedir: SK(4), § 25, kn. 47. Türk doktrininde de yazarlar, gözcünün iştirak statüsünün belirlenmesinde müşahhas olayın

Ancak, bu gözcülük faaliyeti icra edilmemiş olsaydı suçun yine de işlenip işlenmeyeceği konusunda yapılacak ex post araştırma sonucunda varılacak farazî yargıya göre kişinin müsterek fail olarak mı yoksa yardım eden olarak mı sorumlu tutulacağı tayin edilemez. Daha ziyade, gözcülük yapan suç ortağının suçun işlenişine bulunduğu bu iştirak katkısı suçun icrası açısından müessir bir rolü haiz ise, fiil üzerinde fonksiyonel bir hakimiyet kurulmasını sağlıyorsa, müsterek failliğin varlığını kabul etmemiz gerekecektir. Öyle ki, bu durumda suçun icrası adeta bu gözcülük faaliyetine bağlılık arzettiğidir¹¹⁰³.

İfade etmek gerekir ki; hazırlık hareketleriyle suç teşkil eden fiil üzerinde hakimiyet kurulamaz. Müsterek faillik için aranan fiil hakimiyeti için, ilk önce kanunda tanımı yapılan muayyen fiil gözönünde bulundurulmak gerekecektir. Bu itibarla, suçun işlenişine bulunulan katkı, kanunda tanımlanan tipik hareketlere uymayıp, nitelik itibarıyla hazırlık hareketi mahiyetinde ise; ilgili suç ortağını, müsterek fail olarak değil, ancak yardım eden olarak sorumlu tutmamız gerekecektir. Hazırlık hareketi mahiyetinde bir katkıda bulunmakla suçun işlenişine iştirak eden kişi fiilin işlenişinde müsterek bir hakimiyet kuramamaktadır. Daha ziyade, suçun işlenmesini, bilahare suçun icraî hareketlerini gerçekleştirecek olan suç ortağına/ortaklarına havale etmektedir. Bu nedenle, söz konusu suç ortağı, suçun icraî hareketlerini gerçekleştiren suç ortağına/ortaklarına bağımlı hale gelmektedir. Halbuki müsterek faillikte bütün suç ortakları, aralarındaki müsterek işbölümüne dayanarak suçun icrasını gerçekleştirmektedirler. Bu ortak işbölümü gereğince, suçun icrası bütün müsterek faillerin katılımına bağlıdır. Öyle ki, bunlardan bir tanesi kendisine düşen görevi gerçekleştirmediği takdirde bütün plan akamete uğrayacaktır. Örneğin profesyonel bir hırsızla bankayı soymak konusunda anlaşılan banka görevlisi, anlaşma gereğince, profesyonel hırsıza kasanın ne zaman dolduğunu, hangi saatlerde görevlilere yakalanmadan bu işi gerçekleştirebileceğini haber verecektir; buna karşılık, profesyonel hırsız ise, soygunu yalnız başına gerçekleştirecektir. Bu örnekte banka görevlisi suçun icra edilip edilmeyeceğini tamamen profesyonel hırsızın takdirine bırakmıştır. Suçun icraî hareketlerine doğrudan bir katkıda bulunmadığı için, banka görevlisinin soygun ameliyesi üzerinde müsterek hakimiyet kurduğundan bahsedilemez¹¹⁰⁴.

şartlarının gözönünde bulundurulması gerektiği fikrindedirler (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1288; EREM, Genel Hükümler I, 457). Ancak, *Gözübüyük*, gözcülük yapanın "doğrudan doğruya beraber işleyen" (yani, müsterek fail) olarak sorumlu tutulacağı kanaatindedir (GÖZÜBÜYÜK, A. Pulat: Türk Ceza Kanunu Açıklaması, cilt I, 4. bası [tarih yok], sh. 283). Buna karşılık, Yargıtay, hırsızlık suçunda gözcülük yapılması halinde, "doğrudan doğruya beraber işleyen" (yani, müsterek fail) olarak değil; "müzaheret ve muavenetle suçun icrasını kolaylaştıran" (yani, şerik, yardımda bulunan) olarak sorumlu tutulması gerektiği fikrindedir (6. CD. 27.9.1988, 6500/10122: YKD Mart 1989, sh. 428).

¹¹⁰³ ROXIN, LK(10), § 25, kn. 108.

¹¹⁰⁴ ROXIN, Täterschaft, 294/295, 302; aynı yazar, LK(10), § 25, kn. 127. Aynı şekilde HERZBERG, Täterschaft, 65-67; JESCHECK, Lb., 616; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn.

Suç işlemek için oluşturulan örgütün lideri durumundaki kişinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçta müşterek fail olarak sorumlu tutulabilmesi için; suçun işlenişine bulunduğu katkının sadece suçun planlamasına münhasır kalmayıp, aynı zamanda suçun icrası üzerinde de etkide bulunması gerekir. Suçun işleniş planını yapmakla birlikte, icrasına herhangi bir katkısı bulunmayan örgüt lideri, ancak azmettiren veya yardımda bulunan olarak sorumlu tutulabilecektir. Meğer ki bu lider, örgütün diğer üyeleri, mensupları üzerinde hakimiyet kurup, onları ilgili suçun işlenişinde bir araç olarak kullanmış olsun.

Örgüt liderinin müşterek fail olarak sorumlu tutulabilmesi için, icra planlarını yapmak gibi işlenen suçun hazırlık hareketlerinin yanı sıra, uzaktan da olsa, yönlendirmek, sevk ve idare etmek, talimatlar vermek suretiyle suçun icrasına katkıda bulunması gerekir. Yoksa örgütün sadece lideri olmak, bu örgütün faaliyeti zımında işlenen bütün suçlardan dolayı mutlaka müşterek fail olarak sorumlu tutulmayı gerektirmez¹¹⁰⁵.

Örgütün faaliyeti zımında işlenen suçun icrasına bulunduğu katkının niteliğine bakmaksızın örgüt liderinin her halde bu suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulması gerektiği hususundaki iddia, örgüt liderinin esas sorumlu kişi olduğu ve dolayısıyla, örgüt mensupları arasında en tehlikelisini teşkil ettiği düşüncesine dayanmaktadır. Fakat, bu düşünce isabetli değildir. Zira, örgüt lideri de olsa, bir suç ortağını müşterek fail olarak sorumlu tutarken, somut suç vakiasının işlenişine ilişkin icra ettiği fonksiyon dikkate alınacaktır¹¹⁰⁶.

Ancak, örgüte dahil olmakla kişi, örgüte hakim olan hiyerarşideki, emir-komuta zincirindeki yeri itibarıyla, soyut bir araç durumuna da irca edilmiş olabilir. Bu durumda, örgütün işleyiş mekanizmasını kendi hakimiyeti altında tutan kişiler, teşekkülün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda, suçun işlenişine bulundukları katkıya bakılmaksızın, *dolaylı fail* olarak sorumlu tutulmalıdırlar. Suç teşekkülünün bir güç, bir hakimiyet kaynağı olması ve örgüt içinde mevcut hiyerarşik yapı nedeniyle; örgüte mensup olan kişilerin bir suç işlerken serbest iradeleriyle hareket ettiklerini söylemek, her zaman mümkün olmayabilir¹¹⁰⁷.

Yeni TCK'nın TBMM Adalet Komisyonundaki hazırlık çalışmaları sırasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun tanımlandığı 220. maddenin beşinci

825; SCHMIDHAEUSER, Lb., 14/22; SAMSON, SK(4), § 25, kn. 47; RUDOLPHI, Bockelmann-F., 373/374; HARDWIG, JZ 1965, 667; BLOY, 196 vd., 369.

¹¹⁰⁵ ROXIN, Täterschaft, 298-300; aynı yazar, LK(10), § 25, kn. 130; HERZBERG, Täterschaft, 68. Ancak, fiili planlamak, tertipleme şeklindeki hazırlık hareketleriyle de teşekkül liderinin fiil üzerinde hakimiyet kurduğu fikri için bkz. JESCHECK, Lb., 616; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 826.

¹¹⁰⁶ ROXIN, Täterschaft, 299/300, 301; ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Teşekkülü, Düşünceyi Açıklama ve Örgütlenme Hürriyeti*, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Türkân Rado'ya Armağan, cilt LV, yıl 1997, sayı 3, sh. 56; aynı yazar, Suça İştirak, sh. 274 vd.

¹¹⁰⁷ ÖZGENÇ, İstanbul ÜHFM LV (1997), sh. 56.

fikrasında bu hususla ilgili olarak şu şekilde bir düzenleme önerisinde bulundu: “*Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.*” Aslında bu öneride bulunurken, tabir yerinde ise “dokuzu gösterip sekize razı olma”yı amaçlamıştık. Yani aslında kafamızda düşündüğümüz formülasyon “*Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca, **duruma göre fail veya şerik** olarak cezalandırılır.*” şeklinde idi. Fakat, önerdiğimiz fıkra metni Komisyon üyesi Milletvekilleri ve Komisyon toplantılarına katılan Yargıtay temsilcileri tarafından olduğu gibi kabul görünce; bilahare düşündüğümüz formülasyonu kabul ettirme yönündeki girişimlerimizden sonuç alınamamıştır¹¹⁰⁸.

2) Birlikte Suç İşleme Kararı

Müşterek failliğin zorunlu diğer şartı, müşterek failler arasında birlikte suç işleme kararının varlığıdır. Bu karar, belli bir hareketin icrasına ve neticenin meydana gelmesine ilişkin olmalıdır. Öyle ki, müşterek failler arasında fiili müştereken işlemekte olduklarına dair, müşterek hareket ettiklerine dair bir bilginin, iradenin hakim olması gerekir. Müşterek suç işleme kararı, *kast* içinde mütalâa edilmelidir¹¹⁰⁹. Suç ortaklarının suçun işlenişine ilişkin kastlarının farklılık arzemesi (doğrudan kast veya olası kast), müşterek fail olarak sorumlu tutulmalarını engellemez¹¹¹⁰.

Filil üzerindeki fonksiyonel hakimiyet, müşterek failler arasında üzerinde anlaşmaya varılmış bir suç planının varlığını gerekli kılmaktadır. Gerçi **suçun icrası sırasında oluşan birlikte suç işleme kararı dahi müşterek faillik için yeterlidir**¹¹¹¹. Bu itibarla, daha suç planının hazırlandığı sırada karar oluşumuna

¹¹⁰⁸ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Örgütleri*, 12. bası, Ankara, Ocak 2019, sh. 28 vd.

¹¹⁰⁹ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 297; CRAMER, Schönke/Schröder(23) § 25, kn. 94.

¹¹¹⁰ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 299; CRAMER, Schönke/Schröder(23) § 25, kn. 94.

¹¹¹¹ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, **18.09.2012** tarihli ve E. 2012/1-941, K. 2012/1780 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; “Sanıkların (FK, MK ve İD’nin) olay tarihinden önce maktul (Mİ) ve mağdurun (Aİ’nin) ikamet etmekte olduğu mahallede bir kavgaya karıştıkları, olayın yargıya intikal ettiği ve ilgililer hakkında kamu davası açıldığı, ancak yerel mahkemeye getirilip incelenen evraklara göre mağdur ve maktulün bu olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, olay gecesi sanıkların, tanıklarla birlikte bir aracın içinde alkol almakta olan mağdur ve maktulü gördükleri ve önceki olayı bahane ederek mağdur ve maktule sataştıkları, tanıkların ve kolluğun müdahalesi üzerine olayın büyümesinin önlenmediği, aynı gece aradan kısa süre geçtikten sonra sanıkların, yeniden maktul, mağdur ve tanıkların bulundukları yere geldikleri, sanık FK’nin ... sopayla önce maktul Mİ’nin kafasının arka bölgesine vurarak maktulü yere düşürdüğü, daha sonra da aynı sopayla maktulün kardeşi olan Aİ’nin kafasına vurduğu, diğer sanıklar MK ve İD’nin de ... sopalarla mağdur Aİ’nin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurdukları, mağdur ve maktulün yere düşmesi üzerine olay yerinden ayrıldıkları, tanıkların, mağdur ve maktulü evlerine götürdükleri, mağdur ve maktulün ertesi gün ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıkları, maktulün olaydan onyediyedi gün sonra öldüğü, ölü muayene ve otopsi ile adli raporlar doğrultusunda, **maktulün künt kafa travması sonucu öldü-**

iştirak etmek zorunlu değildir. Müşterek faillerin birbirlerini şahsen tanımalarna da gerek yoktur. Yeter ki suçun işlenişine iştirak eden kişiler birlikte suç işleme kararına istinaden fiil üzerinde müşterek bir hakimiyet kursunlar¹¹¹².

Müştereken işlenmesi konusunda karar birliğine vardıkları suçun unsurları arasında kastın haricinde meselâ amaç gibi ziyade bir manevi unsura yer verilmiş ise, bütün müşterek faillerin bu amaçla hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde manevi unsur olarak kastın haricinde amacın araştırıldığı suça müşterek fail olarak iştirak etmek mümkün değildir¹¹¹³. Meselâ bir kasten öldürme suçunda bu suçun temel şekli açısından iki suç ortağı A ve B, müşterek fail olarak sorumlu tutulabilirler. Ancak, bu öldürme fiilinin belirli maksatla işlenmesine ilişkin kasten öldürme suçunun nitelikli şekli açısından, sadece bu maksatla hareket eden suç ortağını fail olarak sorumlu tutabiliriz. Buna karşılık, bu maksatla hareket etmeyen suç ortağını, diğerinin bu maksatla hareket ettiğini bilmesi halin-

ğü, kafatası iç yüzeyinde oksibital kemik orta hattan sol arka fosaysa ve oradan foremen magna uzanan ve çevresinde sonlanan kırık hattı görüldüğü ve sanığın eylemi ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, mağdurun ise kafasına aldığı darbe sonucu hayatı tehlike geçirecek ve vücudunda yaşam fonksiyonlarını ikinci derecede etkileyecek nitelikte kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaralandığı sabit olup, sanıkların ilk tartışma olayının polislerce yatırılmasından kısa süre sonra, olay yerinden uzaklaşmak yerine, olayda kullanılan ve öldürücü nitelikte olduklarında kuşku bulunmayan sopalarla inşaat alanı olan, yakınında yerleşim yeri olmayan ve mağdur ile maktulün yardım istemelerine olanak bulunmayan olay mahalline gelmeleri, mağdur ve maktule vurarak yere düşürmeleri, yerde de vurmaya devam etmeleri, akabinde de olay yerinden kaçmaları, hedef alınan vücut bölgeleri, kullandıkları vasıta ve yaralanmaların nitelikleri ile darbelerin şiddeti birlikte değerlendirildiğinde, sanık FK'nin **maktule yönelik eyleminin kasten öldürme, her üç sanığın katılana yönelik eylemlerinin de kasten öldürme suçuna teşebbüsü oluşturduğunun kabulü gerekir."**

CGK tarafından, karara konu teşkil eden olayda, biri tamamlanmış kasten öldürme suçu diğeri ise kasten öldürme suçuna teşebbüs olarak değerlendirilen birbirinden bağımsız, yani failleri de farklı olan iki ayrı suçun varlığı kabul edilmiştir. Oysa aktarılabiçimi itibarıyla olayda FK, MK ve İD tarafından iştirak halinde Mİ ve Aİ'ye karşı kasten öldürme suçunun işlenmiş olduğunu kabul etmek gerekirdi. Ancak, iştirak halinde hareket eden FK, MK ve İD tarafından Mİ'ye karşı işlenen kasten öldürme suçu tamamlanmış olmakla birlikte, Aİ'ye karşı işlenmiş olan kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır. FK, MK ve İD'yi bu suçlardan dolayı **müşterek fail** sıfatıyla ve ayrı ayrı (**gerçek içtima**) cezalandırmak gerekmektedir.

Oysa CGK, Aİ'ye karşı işlenen ve teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme suçunun iştirak halinde işlendiğini ve bu suç sebebiyle FK, MK ve İD'nin müşterek fail sıfatıyla cezalandırılması gerektiğini kabul etmekle birlikte, Mİ'ye karşı işlenen kasten öldürme suçunun FK tarafından müstakilen işlendiğini kabul etmiştir. Başka bir ifadeyle, suç ortaklarından MK ve İD, Mİ'nin öldürülmesinden sorumlu tutulmamıştır. Bunun, söz konusu karar bakımından bir **hata** olduğunu kabul etmek gerekir.

¹¹¹² MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 298; BGH. 3. Senato, 13.3.1973 (GA 1973, 184/185). Bir hırsızlık suçunda faillerden birisi diğerini çalınan şeyin malikinin rızası olduğu hususunda aldatmak ister. Fakat, bu fail, çalınan şeyin malikinin rızasının bulunmadığının bilincinde olduğunu diğerine hissettirmez. Buna rağmen, hırsızlık suçunu gerçekleştirmeleri halinde, her ikisi de hırsızlık suçunun müstakil faili olarak sorumlu tutulacaklardır; müşterek fail olarak değil: BGH, MDR 1957, 526 (Dallinger).

¹¹¹³ JESCHECK, Lb., 287, 613.

de dahi, kasten öldürme suçunun bu nitelikli şekli açısından ancak yardımda bulunan olarak sorumlu tutabiliriz (*Kısmî müşterek faillik*).

Aralarında birlikte suç işleme kararı olmaksızın birden fazla kişi tarafından aynı konu üzerinde aynı suçun aynı anda işlenmesi halinde, bu kişiler *yan yana müstakil failler*¹¹¹⁴ olarak sorumlu tutulacaklardır. Meselâ, birbirinden habersiz A ve B, müşterek düşmanları C'yi öldürmek için, geçeceği yol üzerinde pusu kurarlar. A ve B, C'ye aynı anda ateş ederler.

Suçun failleri arasında böyle müşterek bir karar mevcut değilse, bunların müşterek fail olarak sorumlu tutulması söz konusu değildir. Bu durumda birbirinden habersiz hareket eden kişilerin sorumluluğunu, bizzat kendi davranışlarını gözönünde bulundurmak suretiyle tayin etmek mümkün olacaktır. Meselâ, A'yı zehirlemek suretiyle öldürmek isteyen B'nin A'ya verdiği zehir müstakilen A'yı öldürecek nitelikte değildir. Fakat A, aynı zamanda C'nin verdiği çok daha etkili olan zehir nedeniyle ölmüştür. Bu durumda B'nin kasten öldürmeye teşebbüsten dolayı sorumluluğu cihetine gidilecektir¹¹¹⁵. Meseleye C açısından bakarsak, şöyle bir ayırım yapmak gerekir: 1) C; B'nin A'ya zehir verdiğiinden haberdar değildir. Bu durumda mesele yine müstakil (yanyana) faillik hükümlerine göre çözümlenecektir¹¹¹⁶. 2) C, B'nin A'ya zehir verdiğiinden haberdardır; fakat, aynı zamanda B'nin verdiği zehirin tek başına A'yı öldürecek nitelikte olmadığını da bilmektedir ve ilk defa kendi vereceği zehirle amaca ulaşmaktadır. Burada fıkrimizce B'yi, yukarıda belirtildiği gibi, kasten öldürmeye teşebbüsten dolayı sorumlu tutmak gerekecektir. Buna karşılık, C'yi ise, ancak tamamlanmış kasten öldürme suçunun müstakil faili olarak sorumlu tutmamız mümkündür. Zira, C, B ve işlediği fiil üzerinde bir hakimiyet kurmuş değildir¹¹¹⁷.

¹¹¹⁴ “Nebentäterschaft”.

¹¹¹⁵ JESCHECK, Lb., 255; ÖNDER, Genel Hükümler II, 99/100.

¹¹¹⁶ Nitekim MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 299.

¹¹¹⁷ Aynı mealde MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 299. Almanya Federal Yüksek Mahkemesinin bir kararına (BGH. 2. Senato, 27.1.1956: BGHSt 9, sh. 180-184) konu teşkil eden olay şöyledir: Bir baba kendisinden nefret ettiği çocuğunun boğazını boğmak üzere sıkır ve kafasına darbeler indirir. Amacına ulaştığını zannederek ve ancak, gerçekte ölmeyip baygın, şuursuz hale düşen çocuğu karısına bırakarak evi terkeder. Fakat, bilahare karısı çocuğun ölmediğini farkedir ve çocuğu kendisi öldürür.

Yüksek Mahkeme, bu olayda karısının işlediği kasden adam öldürme fiiline kocasının (çocuğun babasının) müşterek fail olarak iştirak ettiği görüşündedir. Adam öldürmeye ilişkin olarak karısının işlediği fiil, daha önce kocasının işlediği fiille bağlantılıdır. Bu itibarla, kocanın işlediği fiil, karısının işlediği adam öldürme suçuna etkide bulunmuş olup, meydana gelen netice açısından illi değeri haizdir: BGHSt 9, 182.

Ancak, doğru olarak *Roxin*, bu olayda, müşterek faillik için gerekli olan birlikte suç işleme kararının varlığından bahsedilemediği için, kocanın müşterek fail olarak sorumluluğu cihetine gidilemeyeceği fikrindedir. Bu itibarla, kocanın ancak kasden adam öldürmeye tam teşebbüsten dolayı sorumlu tutulması gerekir: ROXIN, Täterschaft, 288; aynı yazar, LK(10), § 25, kn. 123.

Aynı şekilde, belli bir suçun failine, onun haberi olmaksızın, tek taraflı iradeyle, suçun işlenmesine başlamadan önce veya suçun icrası sırasında yardımda bulunulması halinde müşterek faillik söz konusu olamaz. Ancak, bu ihtimalde, tek taraflı iradesiyle failin fiili işleyişine katkıda bulunan kişiyi her zaman, suçun işlenişine bulunduğu katkının mahiyetine bakmaksızın, yardım eden sıfatıyla, yani şerik olarak sorumlu tutmamız gerekecektir. Şerikliğin bir görünüş şekli olan yardım etme için fail(ler)le yardımda bulunan arasında suç işleme konusunda müşterek iradenin varlığı zorunlu değildir. Meselâ, bankanın önceden soyulacağından haberdar olan görevli tarafından, soyguncuların suçu işlemelelerini kolaylaştırmak amacıyla ve fakat, onların bilgisi dışında, kapının açık bırakılması durumunda; bekçi, ortada müşterek suç işleme kararı mevcut olmamasına rağmen, işlenen hırsızlık suçundan dolayı ancak yardım eden (şerik) sıfatıyla sorumlu tutulacaklardır¹¹¹⁸.

Müşterek faillerden biri kararlaştırılan suçun sınırını şuurlu olarak aşarsa, aşılan bu kısım açısından sınırı aşan suç ortağı, ya müstakil fail olarak; ya da, şayet aşılan kısmın icrasında diğer müşterek faili/failleri vasıta olarak kullandıysa, dolaylı fail olarak sorumlu tutulacaktır¹¹¹⁹. Sözelimi bir kasten yaralama veya yağma suçunu işlemeyi aralarında kararlaştırmış olan müşterek faillerden bir tanesi mağduru kasten öldürürse, bu suç ortağı meydana gelen neticeden müstakil fail olarak sorumlu tutulacaktır.

Gerçi müşterek faillerin birbirlerinin suçun işlenişine bulundukları katkıların tarz ve mahiyetini bütün ayrıntılarına kadar bilmesine gerek yoktur. Suçun kanunî tarifindeki muayyen fiilin sınırları içinde kalmak kaydıyla, müşterek suç işleme kararından, bazı sapmalar halinde dahi müşterek failliğin varlığını kabul etmek gerekecektir. Meselâ konuta girilerek altın ve sair mücevherlerin çalınması kararlaştırılmışken, eve giren müşterek fail, para ve daha başka eşyayı al-

¹¹¹⁸ Bu husus bilahare şeriklik bahsinde tetkik edilecektir. Ancak, burada şu kadarını ifade etmemiz gerekir ki; müşterek failliğin bünyevî özellikleri hakkında yaptığımız bütün açıklamalar, aynı zamanda, bir şeriklik şekli olan *yardımda bulunma* açısından da değer ifade etmektedirler. Birden fazla suç ortağı arasında birlikte hareket etme doğrultusunda bir karar birliğine varılmış olsa bile, bunların hepsinin fiilin icrası üzerinde fonksiyonel, müessir bir hakimiyet kuramaması halinde, bunlar arasındaki ilişki bir tâbiyet (bağlılık) ilişkisi şeklinde tezahür edecektir. Şöyle ki, bu ihtimalde, fiilin üzerinde (müstakil veya müşterek) hakimiyet kuran suç ortağı/ortakları, suç teşkil eden haksızlığı gerçekleştirmektedir(ler). Buna karşılık, suçun işlenişinde hakimiyet kuramayan, bir başka ifadeyle, suçun işlenişine bulunduğu katkı önemsiz olan suç ortağı ise, gerçekleşen haksızlıkla, doğrudan temas halinde olmayıp, fiilin işlenişinde hakimiyet kuran suç ortağı/ortakları vasıtasıyla, yani ancak dolaylı bir temas kurabilmektedir. Bu itibarla, suçun işlenişine yardımda bulunan suç ortağı, ancak fiil üzerinde hakimiyet kuran faille suç teşkil eden haksızlığı gerçekleştirirken hizmet etmektedir ve onun yardımcı durumundadır. Suçun işlenişine bulunulan yardımın hazırlık veya icra aşamasında yapılmış olmasının, yardımda bulunmanın bu niteliği üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir.

¹¹¹⁹ ROXIN, Täterschaft, 286, 289.

miş olabilir¹¹²⁰. Keza, illiyet bağındaki önemsiz sapmalar da müşterek failliğin kabulüne engel değildir¹¹²¹. Açıkça kararlaştırılanın aksine, müşterek faillerden birinin kararlaştırılan suçun nitelikli şeklini ya da bir başka suç tipini gerçekleştirmesi halinde; diğer müşterek failler gerçekleşen bu ağır neticeden, ancak bunun gerçekleşeceğini en azından tahmin etmeleri, hesaba katmaları ve bunun gerçekleşmesine katlanmaları kaydıyla sorumlu tutulabilirler. Gerçekleşen ağır neticeden diğer suç ortaklarını müşterek fail olarak sorumlu tutabilmek için, suçun somut işleniş açısından bir belirlemeye gitmeyip, tamamen kayıtsız kalındığına dair sarih veya zımnî bir müşterek iradenin varlığı gereklidir¹¹²².

Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda, suçun temel şekli açısından aralarında birlikte suç işleme kararı olan suç ortakları müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır. Ancak, meydana gelen ağır netice açısından suç ortaklarının nasıl sorumlu tutulacağı meselesi netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar açısından kabul edilen sisteme bağlı olarak halledilecektir. Önce ifade etmek gerekir ki, meydana gelen ağır neticeye müşterek faillerden birisi kasten sebebiyet vermişse, gerçekleşen ağır netice açısından bu suç ortağını müstakil fail olarak sorumlu tutmak gerekecektir. Bu netice dolayısıyla diğer suç ortaklarının sorumluluğu cihetine gidilemeyecektir¹¹²³.

Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar açısından objektif sorumluluğun kabul edildiği 765 s. TCK'nın sisteminde (örneğin m. 452), meydana gelen ağır netice açısından bütün müşterek failleri taksir dolayısıyla kusurlu veya tamamen kusursuz olmaları halinde dahi sorumlu tutmak gerekecektir. Ancak, taksirli suçlarda müşterek failliğin söz konusu olmadığı için buradaki sorumluluk şekli birer müstakil sorumluluk şekli olarak anlaşılmalıdır.

Buna karşılık, netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda kusursuz sorumluluğu kabul etmeyen, gerçekleşen ağır netice açısından en azından taksir dolayısıyla kusurluluğun varlığını gerekli gören yeni TCK sisteminde ise (m. 23), diğer müşterek

¹¹²⁰ Suçun objesinin müşahhaslaştırılması perspektifinden hareketle meseleye çözüm getiren bir karar: BGH. 5. Senato, 2.11.1965 (MDR 1966, 197 -Dallinger-).

¹¹²¹ JESCHECK, Lb., 614.

¹¹²² ROXIN, LK(10), § 25, kn. 121; HERZBERG, Täterschaft und Teilnahme, 62/63.

¹¹²³ ROXIN, LK(10), § 25, kn. 122. Nitekim, bir olayda, sadece dövmek için aralarında anlaşmaya varan üç kişi (F, H ve C), mağduru döverlerken, F'nin silahıyla mağduru öldürmek istediği anlaşılır. H ve C, F'yi engellemek için ellerinden gelen gayreti sarfederler; fakat, engel olamazlar. F, mağduru vurarak öldürür. Yargıtay, doğru olarak, F, H ve C'yi kasden müessir fiil suçundan dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutarken; mağdurun öldürülmesi fiilinden sadece F'nin sorumlu olduğu, buna karşılık, H ve C'nin sorumlu tutulamayacağı fikrindedir: CGK. 5.12.1988, 1-470/514 (YKD Mayıs 1989, 719-721). Ancak, *Jescheck*'e göre, suç ortağının meydana gelen ağır neticeyi kasden, taksirle veya kusursuz olarak gerçekleştirmesi, diğer suç ortaklarının netice sebebiyle ağırlaşan suçlara ilişkin hükümler çerçevesinde gerçekleşen bu ağır neticeden sorumlu tutulmalarına engel teşkil etmez: JESCHECK, Lb., 517, 614, 625.

failler bu ağır netice açısından en azından taksir dolayısıyla kusurlu bulunmaları halinde sorumlu olacaklardır¹¹²⁴.

Suçun konusundaki önemsiz yanılığın müşterek faillerin sorumluluğu üzerinde bir etkisi yoktur¹¹²⁵. Ancak, bazı yanılığ hallerinde problemle karşılaşılacaktır: Meselâ mala zarar verme suçunun (m. 151) müşterek faillerinden birisi yanılarak, diğer bir müşterek failin malına zarar verirse; mal sahibi müşterek fail, bu fiilden sorumlu tutulabilecek midir?

Bu hususa ilişkin Alman Federal Yüksek Mahkemesinin bir kararına¹¹²⁶ esas teşkil eden olay şu şekilde cereyan eder: Üç silahlı kişi, bir gece soygun yapmak amacıyla, gıda maddesi satan bir markete girmek için teşebbüste bulunurlar. Bu üç suç ortağı arasında önceden varılan anlaşmaya göre, suçun icrası sırasında içlerinden birinin yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi halinde silah kullanacaklardır. Bu üç müşterek fail, hırsızlık amacıyla markete girecekleri sırada fark edildikleri için, kaçmak zorunda kalırlar. Karanlıkta kaçarlarken suç ortaklarından M, arkasından gelen ayak sesleri duyar ve takip edilip yakalanacakları zehabına kapılır. Bunun üzerine, arkasından koşarak gelen kişiye öldürmek kastıyla silahıyla ateş eder. Fakat, M'nin gerçekte ateş ettiği kişi, kendilerini takip eden sair bir kimse olmayıp, kendisi gibi kaçmakta olan diğer suç ortağı P'dir. M'nin silahından çıkan mermi P'nin kolunu hafifçe sıyrır¹¹²⁷.

Bu olayda ateş eden M'nin kasten öldürmeye teşebbüsten dolayı sorumlu tutulacağı hususunda tereddüt edilmemektedir. Aynı şekilde, üçüncü suç ortağı da, gerektiğinde silah kullanacaklarına dair karara iştirak etmesi ve suç planını birlikte icraya koymaları itibarıyla, bu suça müşterek fail olarak iştirak etmiştir. Fakat, mesele, aynı karara iştirak etmekle beraber, bu karar gereğince hareket eden M'nin yanılması sonucu, arkadan takip eden kişi değil de, diğer suç ortağı P'nin çok hafif bir şekilde isabet alması karşısında, P'nin sorumlu tutulup tutulmayacağı, sorumlu tutulacaksa, bu sorumluluk statüsünün ne olacağı hususunda ortaya çıkmaktadır.

Federal Yüksek Mahkeme, P'nin gerçekleştirecek bütün neticeleri kendisine mal etmesi, bunları kabullenmesi itibarıyla, onun da kasten öldürme suçuna (elverişsiz) teşebbüsten dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutulması gerektiği kanaatinde¹¹²⁸.

¹¹²⁴ ROXIN, LK(10), § 25, kn 122; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 300; CRAMER, Schöнке/Schröder(23), § 18, kn. 7; JAKOBS, Lb., 513.

¹¹²⁵ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 300.

¹¹²⁶ BGH, 4. Senato, 23.1.1958 (BGHSt 11, 268-272).

¹¹²⁷ Benzer bir örnek olay ve çözüm şekli için bkz. ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku (2), sh. 45 vd.

¹¹²⁸ BGHSt 11, 272.

Failliğin tayini için, kanunî tarifteki muayyen fiilin soyut bir şekilde (meselâ, mağdurun kimliğinden soyut olarak) gerçekleştirilmesi yeterlidir.¹¹²⁹ İster dolaylı faillik olsun, ister müşterek faillik olsun; failliğin tayininde suçun kanunî tarifindeki unsurların haricinde bir somutlaştırmaya gidilmediği hususunda doktrinde fikir birliği hakimdir. Ancak, böyle bir somutlaştırma azmettirme ve yardım etme için gereklilik arzedecektir. Çünkü, azmettirme ve yardım etme, muayyen bir suç açısından söz konusudur.¹¹³⁰

Bu itibarla, gerek yukarıdaki mala zarar verme örneğinde, gerek Federal Yüksek Mahkemenin söz konusu kararına konu teşkil eden olayda, bütün suç ortaklarını müşterek fail olarak nitelendirmek gerekir. Ancak, mala zarar verme suçunda malına zarar verilen kişi, müşterek suç işleme kararının aksine, diğer bir müşterek faildir. Bu nedenle, malına zarar verilen müşterek fail, mala zarar verme suçuna (elverişsiz) teşebbüsten dolayı sorumlu tutulacaktır.¹¹³¹ Aynı şekilde, mezkûr karara konu teşkil eden olayda yanlışlıkla kendisine ateş edilen diğer müşterek fail, kasten öldürmeye (elverişsiz) teşebbüsten dolayı sorumlu tutulacaktır.¹¹³²

Bir olayda Yusuf, Zülfü, Halit ve Zeki, Mehmet'i korkutmak amacıyla geceleyin evine doğru hep birlikte ateş etmeye başlamışlardır. Suç ortaklarından "Zeki tabanca ile, yanındaki Halit av tüfeğiyle 20 metreden; ... Yusuf ve Zülfü ise, ... av tüfekleriyle 40 metre mesafeden ... ateş etmeye başlamışlardır". "... Yusuf ve Zülfü tarafından yapılan atışlar sırasında hangisinin av tüfeğinden çıktığı belirlenemeyen ... saçma tanesi, hedefte hata sonucu Zeki'ye isabet ederek ölümüne neden olmuştur". Yargıtay'a göre; "... Yusuf ve Zülfü'nün ... fiillerinin *müessir fiil sonucu ölümüne neden olma* şeklinde nitelendirilmesinde zorunluluk" vardır. Yani, bu iki suç ortağının Zeki'nin öldürülmesinden dolayı 765 s. TCK'nın 452. maddesinin 1. fıkrasına ve 463. maddesine göre cezalandırılmaları gerekir.¹¹³³

Önce belirtmek gerekir ki, bu dört suç ortağının müştereken işlemeye karar verdikleri suç, Mehmet'i korkutmaktır. Bu itibarla, Mehmet'i korkutmak açısından bu dört suç ortağı da müşterek faildir.

Ancak, Mehmet'i korkutmak için ateş eden dört suç ortağından Yusuf ve Zülfü'nün silahlarından birinden çıkan bir saçma tanesi Zeki'nin ölümüne sebebiyet

¹¹²⁹ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 300.

¹¹³⁰ Bu itibarla, genel olarak herhangi bir kimseyi öldürmeye karar veren bir şahıs, muayyen birini öldürmek için azmettirilebilir. Bu husus, şerikliğin bağlılığı prensibinden kaynaklanmaktadır. Şeriklikten bahsedebilmek için, fail tarafından işlenen müşahhas bir esas fiile ihtiyaç vardır. Çünkü, şeriklik haksızlık muhtevasını ancak müşahhas bir esas fiilden almaktadır.

¹¹³¹ JESCHECK, Lb., 612; SAMSON, SK(4), § 25, kn. 49; CRAMER, Schönke/ Schröder(23) § 25, kn. 89, 96.

¹¹³² JESCHECK, Lb., 612, JAKOBS, 513; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 259; BAUMANN, Beiträge, 187/188.

¹¹³³ CGK. 5.10.1987, 1-229/440 (YKD Nisan 1988, sh. 545 vd.).

vermiştir. Suç ortaklarının kastı, öldürme veya yaralama suçunu işlemeye yönelik olmadığı için, burada meseleyi iştirak kurallarına göre çözümleyemeyiz. Çünkü, Zeki'nin ölümüne taksirle sebebiyet verilmiştir. Dolayısıyla, Kararda olduğu gibi, Zeki'nin ölümünden Halit'in de sorumluluğu cihetine gidilip gidilmeyeceğinin tartışılmaması isabetlidir. Fakat, Zeki'nin ölümüne sebebiyet veren saçmanın, Yusuf ve Zülfü'nün hangisinin silahından çıktığı anlaşılamamıştır. Bu durumda, kanaatimizce, *in dubio pro reo* kuralı gereğince, her iki suç ortağı Yusuf ve Zülfü'nün, Zeki'nin öldürülmesinden dolayı *ceza hukuku açısından* sorumlu tutulmaması gerekir¹¹³⁴.

Bu itibarla, Ceza Genel Kurulu'nun görüşüne iştirak etmiyoruz. Şöyle ki; bir taraftan suç ortaklarının korkutmak maksadıyla ("kararından caydırmak amacıyla") ateş ettikleri kabul ediliyor; öteki taraftan "müessir fiil sonucu ölümüne neden olma"ktan dolayı mahkûmiyet cihetine gidilmesi gerektiği fikri savunuluyor. Yani, bu durumda 765 s. TCK'nın 452. maddesinin 1. fıkrasının tatbik edilmesi gerektiği savunuluyor. Halbuki işlenmek istenen, kastedilen suç, yaralama (müessir fiil) suçu olmadığı için; bu ihtimalde 452. maddenin tatbik kabiliyeti mevcut değildi.

Şayet suç ortaklarının kastı, yani müşterek suç işleme kararı Mehmet'e karşı yaralama suçunu işlemek ise; bu durumda bütün suç ortaklarının kasten yaralama suçuna teşebbüsten dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutulmaları gerekir. Bu ihtimalde Zeki'nin öldürülmesinden Halit'i sorumlu tutmak mümkün değildir. Yusuf ve Zülfü'den hangisinin Zeki'nin ölümüne taksirle sebebiyet verdiği sabit olsaydı, bu suç ortağı ayrıca taksirle öldürme suçundan sorumlu tutulacaktı. Ancak, somut olayda ölümüne taksirle sebebiyet verilen Zeki'ye Yusuf ve Zülfü'den hangisinin silahından çıkan merminin isabet ettiği belli olmadığı için, kanaatimizce, *in dubio pro reo* kuralı gereğince, her ikisinin de Zeki'nin ölümünden dolayı *ceza hukuku açısından* sorumlu tutulmaması gerekir.

765 s. TCK'nın hiçbir meşruluk temeli olmayan 463. maddesinin de bu olaya tatbiki mümkün değildi.

Ancak, Esas Mahkemesi, gerek ilk kararında, gerek direnme kararında, bütün suç ortaklarının öldürmek kastıyla hareket ettikleri görüşündedir. Bu durumda, bütün suç ortaklarının Mehmet'i öldürmeye teşebbüsten dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutulmaları gerekir.

Olayda ayrıca suç ortaklarından Yusuf ve Zülfü'den birinin silahından çıkan mermiyle hedefte sapma sonucu diğer bir suç ortağı Zeki ölmüştür. Burada Zeki'nin ölümüne taksirle sebebiyet verilmiştir. Dolayısıyla, müşterek suç işleme kararının haricinde gerçekleşen bu neticeden Halit'i sorumlu tutmak mümkün

¹¹³⁴ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 304/305.

değildir. Fakat, taksirle ölümüne sebebiyet verilen Zeki'ye isabet eden bir tek merminin Yusuf ve Zülfü'den hangisinin silahından çıktığı anlaşılamamıştır. Bu durumda, kanaatimizce, *in dubio pro reo* kaidesi gereğince, Yusuf ve Zülfü'nün her ikisinin de Zeki'nin öldürülmesinden dolayı *ceza hukuku açısından* sorumlu tutulmamaları gerekir.

765 s. TCK'nın mağdurun kimliğinde veya suçun konusunda yanlışlıklarına ilişkin müşterek bir çözüm getiren (*tek suça göre sorumluluk*) 52. maddesi düzenlemesinin isabetsizliği bu olay karşısında iyice anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle, 52. madde düzenlemesi karşısında böyle bir olayda, yani Zeki'nin öldürülmesine ilişkin kastları olmayan Yusuf ve Zülfü'den hangisinin silahından çıkan merminin Zeki'ye isabet ettiğinin tespit edilememesi halinde, bu iki şahsın sorumlulukları cihetine gidilmesi oldukça güçleşecektir. Bu itibarla, Esas Mahkemesinin bu olayda 52. madde hükmünün tatbik edilmesi ve dolayısıyla, Yusuf ve Zülfü'nün her ikisinin de kasten öldürme suçundan sorumlulukları cihetine gidilmesi gerektiği doğrultusundaki görüşünü, zorlama bir görüş olarak telâkki etmekteyiz.

İcrasına henüz başlanmış olan bir suçun işlenmesine bilahare müşterek fail olarak iştirak etmek mümkündür. Fakat, icrasına henüz başlanmış bir suçun işlenişine sonradan iştirak eden suç ortağının müşterek fail olarak sorumlu tutulabilmesi için, müşterek suç işleme kararının yanı sıra, bu suç ortağının suçun işlenişine bulunduğu katkının fiil üzerinde fonksiyonel bir hakimiyet kurmaya yetecek ağırlıkta olması gerekir. Sonradan suçun işlenişine müşterek fail olarak iştirak edebilmek için, diğer müşterek faillerin buna muvafakat göstermeleri gerekir. Buna göre, bir hırsızlık suçunda çalınan eşyanın nakledilmesine katılmak, müşterek fail olarak sorumluluğu gerektirir¹¹³⁵. Ancak, suçun icrası tamamlandıktan sonra, olanların bilincinde olmaya rağmen, vakıya müdahale etmek, artık müşterek fail olmayı gerektirmez¹¹³⁶.

Almanya Federal Yüksek Mahkemesinin bir kararına¹¹³⁷ konu teşkil eden olay şu şekilde cereyan eder: Kapısını kırarak bir bakkalı soyan P, gıda maddelerinin bir kısmını alıp, arkadaşı N'nin evine götürür. P, N'ye bu maddeleri bir hırsızlık sonucunda elde ettiğini söyler ve, aralarında bilahare bölüşmek vaadiyle bakkalda kalan diğer eşyayı da beraberce almalarını telkin eder. Bu defa her ikisi birlikte kalan eşyayı alır ve aralarında bölüşürler.

Federal Yüksek Mahkeme, P'nin yanı sıra N'yi de hırsızlık suçunun nitelikli şekline (kapı kırarak hırsızlık suçuna)¹¹³⁸ müşterek fail olarak sorumlu tutmuş-

¹¹³⁵ ROXIN, LK(10), § 25, kn. 134.

¹¹³⁶ Bu ihtimallerde suç eşyasının saklanması vs. gibi suçların oluşup oluşmadığı araştırılmalıdır.

¹¹³⁷ BGH 3. Senato, 24.4.1952 (BGHSt 2, 344-348).

¹¹³⁸ Alman CK. § 243, fıkra 1, bend 1.

tur. N, bilahare suçun işlenmesine iştirak etmekle, P'nin daha önce işlediği fiillere muvafakat gösterdiğini beyan etmektedir. Bu sebeple, müşterek fail sıfatıyla N'nin de bir bütün olarak suçun nitelikli şeklinden sorumlu tutulması gerekecektir. Yüksek Mahkemenin kararına göre, suçun işlenişine sonradan ve fakat tamamlanmadan önce iştirak eden kişinin, suça ilişkin daha önceden gerçekleşmiş olan nitelikli unsurlarının şuurunda olmak kaydıyla, müşterek fail olarak sorumlu tutulması gerekir. Ancak, suçun işlenişine ilişkin bilgiye, tasvibe ve hatta suçun semerelerinden istifade etmeye rağmen, söz konusu suç artık tamamlandıktan sonra müşterek fail olarak suça iştirak mümkün değildir¹¹³⁹. Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının gerekçesinde devamla, bir şeriklik türü olan yardım eden olarak sorumluluk için yapılan yardımın suçun icrasının hangi aşamasında yapıldığının iştirak statüsüne herhangi bir etkisinin olmadığını ve dolayısıyla, müşterek faillik için farklı düşünmenin bir haklılık yönünün bulunmadığı açıklanmıştır¹¹⁴⁰.

Fakat, Yüksek Mahkemenin görüşünün aksine, suçun işlenmesine bilahare iştirak eden kişiyi, iştirakinden önce gerçekleşmiş olan suçun nitelikli unsurlarından dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutamayız¹¹⁴¹. Müşterek fail, diğer müşterek fail(ler)le birlikte suç işleme kararına istinaden gerçekleştirdiği fiilden sorumludur. Fakat, kendi iştirakinden önce, gerçekleşmiş olan kapı kırmak şeklindeki hırsızlık suçunun nitelikli unsuru, bu müşterek suç işleme kararına dahil olmayan bir vakiyadır ve bilahare suçun işlenişine iştirak etmekle daha önce işlenen fiilleri muvafakat etmek, müşterek fail olarak sorumluluğa esas teşkil edemez¹¹⁴². Bu şekildeki muvafakat, belli şartlarda hırsızlık suçunun bu nitelikli unsuru açısından önceki failin fiiline ancak yardım etme olarak yorumlanabilir¹¹⁴³.

Buna göre, meseleyi şu şekilde düşünmek gerekir: N, P'nin işlediği nitelikli hırsızlık suçuna bilahare iştirak etmiştir. N'nin iştirak ettiği anda hırsızlık suçunun nitelikli unsuru olan kapı kırmak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Hırsızlık suçunun bu nitelikli unsuru açısından N'nin iştiraki ancak yardımda bulunma olarak nitelendirilecektir. Ancak, kapı kırıldıktan sonra sair eşyanın alınmasına ilişkin fiil açısından, yani hırsızlık suçunun temel şekli açısından, P ve N, müşterek faildirler. Ancak, N'nin bilahare iştiraki hırsızlık suçunun nitelikli unsuru olan kapı kırma fiilini fail olarak gerçekleştiren P'nin fiiline sadece yardım etme ola-

¹¹³⁹ BGHSt 2, 346.

¹¹⁴⁰ BGHSt 2, 345/346. Yüksek Mahkemenin bu kararı, doktrinde de taraftar bulmuştur: WELZEL, Lb., 107; BLEI, Allgemeiner Teil(17), 247; BAUMANN/WEBER, 540; KOHLRAUSCH/LANGE(43), 174.

¹¹⁴¹ ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, 289 vd.; aynı yazar, LK(10), § 25, kn. 136, 137.

¹¹⁴² Aksi fikir, ancak iştirak şekillerinin ayırımındaki sübjektif teoriyi benimsemekle savunulabilir.

¹¹⁴³ Aynı mealde MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 304; WESSELS, Allgemeiner Teil(19), 153.

rak nitelendirilebilir. N'yi hırsızlık suçunun nitelikli şeklinin müşterek faili olarak sorumlu tutamayız¹¹⁴⁴.

Bir suçun işlenişine sonradan iştirak eden kişinin, müşterek fail olarak sorumlu tutulabilmesi için, suçun işlenişine bulunduğu katkıyla bu suçun bütünü üzerinde müşterek bir fiil hakimiyeti sağlaması gerekir. Bir başka ifadeyle, suçun işlenişine sonradan iştirak eden şahıs, suçun işlenişine bulunduğu katkıyla önceden müstakil fail olarak suçun icra hareketlerini gerçekleştirmeye başlayan şahsın gerçekleştirdiği vakıalar üzerinde de müşterek hakimiyet kurmalıdır ki, müşterek fail olarak sorumlu tutulabilsin¹¹⁴⁵. Önceden işlenen vakıaları mücerret tasvip, bu vakılardan dolayı müşterek fail olarak sorumluluğu haklı kılmaz. Meselâ, mütemadî (kesintisiz) suçlarda suçun icrası sona edinceye kadar temadî eden fiile müşterek fail olarak iştirak etmek mümkündür. Çok hareketli suçlarda bilahare suçun işlenişine iştirak eden şahıs, şayet fiilin bütünü üzerinde müşterek bir hakimiyet kurabiliyorsa, müşterek fail olarak sorumlu tutulacaktır¹¹⁴⁶. Meselâ X'i soymaya gayret eden A'ya karşı kendisini savunan X, bilahare olaya müdahale eden B tarafından tesirsiz hale getirilir. Bu suretle her ikisi birden yağma suçunu müştereken işleyerek, fiilin bütünü üzerinde müşterek hakimiyet tesis etmektedirler. Çünkü, B'nin bilahare olaya müdahalesiyle fiilin işlenişini ancak imkân dahilinde olmuş veya en azından kolaylaştırmıştır¹¹⁴⁷. Buna karşılık, meselâ şu olayda A, yağma suçundan dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutulamayacaktır: A ve B, X'i müştereken dövmeyi kararlaştırıp fiili icraya korken, B, A'nın haberi olmaksızın X'in cüzdanını da çalar. Kasten yaralama suçunun her iki müşterek faili X'i döverken, bu durumdan istifade eden B, ayrıca X'in cüzdanını alır. B, bilahare durumdan A'yı da haberdar eder ve A, B'nin yağmalamak maksadıyla cebir kullandığına dair fiilini tasvip ettiğini beyan eder¹¹⁴⁸.

3) Özgü Suçlarda Müşterek Faillik

Özgü suçlar, *sırf yükümlülük suçları* ile *hakimiyet ve yükümlülük suçları* olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Sırf yükümlülük suçlarında fail olabilmek için, kişinin ceza hukuku dışında, başka bir hukuk disiplininin kaynaklanan özel bir yükümlülük altında olması, bir başka

¹¹⁴⁴ Aynı mealde HERZBERG, Täterschaft und Teilnahme, 71/72; JESCHECK, Lb., 615 ve dn. 18; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 820, 873; SAMSON, SK(4), § 25, kn. 48; SCHMIDHAEUSER, Lb., 14/21; CRAMER, Schönke/Schröder(23), § 25, kn. 91; WESSELS, Allgemeiner Teil(19), 153; BOCKELMANN/VOLK, § 23 II 1.

¹¹⁴⁵ GÖSSEL, Karl Heinz: Sukzessive Mittäterschaft und Täterschaftstheorien, Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck, Berlin, 1985, sh. 554 vd.; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 304.

¹¹⁴⁶ GÖSSEL, Jescheck-F., 556/557; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 304.

¹¹⁴⁷ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 302. Benzer bir örnek için bkz. GÖSSEL, Jescheck-F., 555/556.

¹¹⁴⁸ Fakat, Federal Yüksek Mahkeme, A'nın da yağma suçundan dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutulması gerektiği kanaatindedir: JZ 1981, sh. 596.

ifadeyle, özel faillik niteliğini taşıması yeterlidir (intraneus). Kanun bu yükümlülüğü ihlâl eden belirli bir fiili tanımlamadığı için, fiilin işlenişi üzerinde hakimiyet kurulması faillik açısından aranmayacaktır. Bu nedenle, birlikte suç işleme kararıyla hareket etmeleri kaydıyla, suçun işlenişine iştirak eden ve özel faillik niteliğini taşıyan bütün suç ortakları, müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır.

Buna karşılık, faillik için özel yükümlülük şartının arandığı suçlarda, kanun kural olarak ayrıca suç tipini oluşturacak belirli bir fiili de tanımlamaktadır. Sadece özel faillik niteliğine sahip olmak, bu tür suçlardan dolayı fail olarak sorumlu tutulabilmek için yeterli değildir. Bunun için, özel faillik niteliğinin yanı sıra, ayrıca fiil üzerinde hakimiyet kurulması gerekir. Buna göre, meselâ TCK'nın 204. maddesindeki resmî belgede sahtecilik suçunun işlenişine iştirak eden kamu görevlisinin, bu suçun nitelikli şekli (m. 204, f. 2) açısından müşterek fail olarak sorumlu tutulabilmesi için, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, ayrıca evrakta sahtekârlık fiili üzerinde müşterek hakimiyet kurması gerekir. Özel faillik niteliğini taşımakla birlikte, suçun işlenişine bulunduğu iştirak katkısı fiil üzerinde müessir (fonksiyonel) bir hakimiyet kurulması için yeterli görülmeyen suç ortağı, bu suçta ancak yardım eden olarak şerik sıfatıyla sorumlu tutulacaktır¹¹⁴⁹.

Meseleyi şu şekilde de düşünmek mümkündür: Resmî belgede sahtecilik suçunu özel faillik niteliğini (kamu görevlisi) taşıyan kişi (A) ile herhangi bir şahıs (B) birlikte de işleyebilirler. Bu durumda her iki suç ortağı sahte resmî evrak düzenleme vakıası üzerinde müşterek hakimiyet kurmuş olabilirler. Bu durumda resmî belgede sahtecilik suçunun temel şekli (m. 204, f. 1) açısından A ile B arasında müşterek failliğin varlığını kabul etmek gerekecektir ve özel faillik niteliğini taşımayan B'yi 204. maddenin birinci fıkrasına istinaden fail olarak sorumlu tutmak gerekecektir. Resmî belgede sahtecilik suçunun nitelikli şekli (m. 204, f. 2) açısından ise, özel faillik niteliğini taşıyan A'yı müstakil fail olarak sorumlu tutmak gerekecektir. B'yi ise, bu suçun *nitelikli şekline* ancak yardım eden, yani şerik olarak sorumlu tutabiliriz. Fakat işaret etmek gerekir ki; özel faillik niteliğini taşımayan B tek bir fiille bir suçun temel şeklinin işlenişine fail olarak, nitelikli şeklinin işlenişine ise şerik olarak iştirak etmektedir. *Failliğin şerikliğe göre aslîliği kuralı* gereğince B'yi sadece fail olarak sorumlu tutulması gereken suçtan dolayı cezalandırmak gerekecektir^{1150,1151}.

¹¹⁴⁹ Rüşvet suçuna ilişkin olarak verdiği bir kararda Yargıtay 5. Ceza Dairesi, paranın bulunduğu zarfı C. Savcısına götürülen şahsı, rüşvet suçunun icraî hareketlerini gerçekleştirmiş olmasına rağmen, "rüşvete konu olan muamele ile doğrudan ilgisi" olmadığı gerekçesiyle şerik olarak sorumlu tutmamaktadır (Yargıtay 5.CD. 25.1.1974 [İçel/Yenisay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, 2. bası, 1989, sh.760]; keza Yargıtay 6.CD. 29.3.1983, 11385/2629 [Çağlayan I, 785]).

¹¹⁵⁰ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 290/291.

¹¹⁵¹ Yüksek Mahkeme, örneğin memur olmayanların memur tarafından işlenen ve ancak memurlar tarafından işlenebilen bir suçta iştirak edebileceğini müteaddit kararlarında teyid etmektedir

4) İhmalî Suçlarda Müşterek Faillik

Belli neticelerin önlenmesi açısından güvence yükümlülüğü, belli bir davranışta bulunma yükümlülüğü altındaki birden fazla kişinin, bu yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, kanunî tarifte yer alan belli neticenin gerçekleşmesini engellememeleri halinde, müşterek faillik söz konusudur. Ancak, bunun için teminat yükümlülüğü altındaki suç ortaklarının aralarındaki müşterek karara istinaden, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerekir. Şöyle bir örnek düşünebiliriz: Bir yoğun bakım istasyonunda veya acil serviste çalışan hasta bakıcıları maaşlarının azlığı nedeniyle, boykot maksadıyla, bir süre işi durdurmayı kararlaştırırlar. Bunun sonucunda, kendilerine gerekli bakım ve sağlık hizmeti sunulamadığı için, bir veya birkaç kişi ölmüş olabilir.

Sorun, işlenen icraî bir suça ihmalî davranışla müşterek fail olarak iştirak edilebilip edilemeyeceği noktasındadır. Belli bir davranışta bulunma, kanunî tariftteki muayyen neticeyi önleme yükümlülüğü altında bulunması nedeniyle; kişi bir başkasının işlediği icraî suçun işlenişini önlememekle, bu yükümlülüğe aykırı hareket etmiş olmaktadır; dolayısıyla, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen garantör, (görünüşte) ihmalî bir suç işlemektedir. Bu kişi aynı zamanda bir başkasının icraî suçunun işlenmesini önlememekle, ona yardımda bulunmaktadır. Böyle bir durumda, failliğin şerikliğe göre aslîliği kuralı karşısında, aslî-talı norm ilişkisine ilişkin prensip gereğince¹¹⁵², kişiyi (görünüşte) ihmalî suç faili olarak sorumlu tutmak gerekecektir. Bu ihtimalde icraî davranış fail(ler)i ile ihmalî davranışta bulunan garantör şahıs arasında bir irade birliğinin bulunmasına da gerek yoktur. Ancak, aralarında irade birliği oluşsa bile, sırf güvence yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suretiyle bir başkasının icraî suçuna müşterek fail olarak iştirak etmek mümkün değildir.

5) Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik

Taksirli suçlarda müşterek failliğin söz konusu olamayacağı fikri doktrinde hakim bulunmaktadır. Gerçi, özellikle Türk Hukukunda bazı yazarlar, her ne kadar netice öngörülmemişse de, icra edilen fiil açısından birlikte hareket etme kararının varlığını esas alarak, taksirli suçlar açısından müşterek failliğin mümkün olduğunu iddia etmektedirler¹¹⁵³.

(CGK. 21.12.1944, 20/23 [Dönmezer/Erman II, no. 1241 dn. 200]; 5. CD. 2.7.1953, 2243/2444 [Dönmezer/Erman II, no.1241 dn. 200]; 5. CD. 10.2.1976, 314/231 [YKD 1976, sh. 922]; 5. CD. 7.7.1982, 2403/2736 [YKD 1983, 612]; 5. CD. 22.5.1986, 1345/2609 [YKD 1987, 239 vd.]; 8. CD. 20.6.1984, 2704/3474 [YKD 1985, 136 vd.]). Ancak, memur olmayan kişinin iştirak statüsünün tayini yine genel kurallara göre yapılmaktadır. Nitekim Yargıtay, iştirak halinde işlenen depodaki tekel malları üzerindeki zimmet suçunda, mallar üzerinde denetim sorumluluğu bulunan Tekel idare memuru M'nin yanısıra, "taşıyıcı işçi S'nin de ihtilâs suçunun aslî iştirakçisi" yani faili(!) olabileceğine karar vermiştir (5. CD'nin 22.5.1986 tarihli kararı).

¹¹⁵² İÇEL, Suçların İçtimai, sh. 214.

¹¹⁵³ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1251, 1252; İÇEL, Taksir, sh. 174; EREM, Genel Hükümler I, 415/416, DONAY, İstanbul ÜHFM 35(1970), sh. 517. Alman Hukukunda ise, MEZGER,

Birlikte hareket edilmesi zımındaki karar, sadece objektif özen yükümlülüğünün ihlâli mahiyetindeki fiilin işlenmesine yöneliktir. Halbuki, taksirli suçlarda gerçekleşmesi zorunluluk arzeden örneğin bir insanın ölmesi veya yaralanması neticesi öngörülmediği için; bu netice açısından bir karar birliğinden bahsedilemez. Bu itibarla; ancak objektif özen yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden ve dolayısıyla, bir haksızlık ifade eden fiilin işlenişine matuf olarak kişiler arasında bir karar birliği oluşabilir. Şayet soyut olarak bu haksızlık cezaî müeyyide altına alınmış olsaydı; bu haksızlığı birlikte gerçekleştiren kişiler, müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardı. Ancak, Kanuna göre, objektif özen yükümlülüğüne aykırı davranış neticesinde meselâ bir insanın ölmesi veya yaralanması halinde suç oluşacaktır. Bu neticeye sebebiyet veren haksız fiili gerçekleştiren kişiler arasında söz konusu netice açısından bir karar birliğinin varlığından sözedilemez.

D. Dolaylı Faillik

Dolaylı faillik, 37. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, “*suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.*”

Suç teşkil eden haksızlık bazen bir diğer kişinin *vasıta* olarak kullanılması suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu durumda, arka plandaki şahıs, suçun icraî hareketlerini gerçekleştiren şahsın ve hareketinin üzerinde üstün hakimiyet kurmaktadır ve bu hakimiyet, arka plandaki şahsa **dolaylı faillik** vasfını kazandırmaktadır.

Arka plandaki şahsın suçun icraî hareketlerini gerçekleştiren şahıs ve hareketi üzerinde hakimiyet kurmasını tedarik eden hususlardan bir tanesi ön plandaki şahsın *yanılgı* içinde olmasıdır. Söz konusu yanılgı suçun teşekkülü açısından zorunlu olan kastı bertaraf edebileceği gibi, kanunî tarife uygun haksızlığın gerçekleşmesi açısından etkili olan hususlarda da meydana gelebilir. Ancak, kanunî tarife uygun haksızlığın gerçekleşmesine etkili olmayan hususlardaki bir yanılgı, arka plandaki şahsın fiil üzerinde hakimiyet kurabilmesi için yeterli değildir.

Arka plandaki şahsın fiil üzerinde hakimiyet kurabilmesini sağlayan diğer bir husus, fiili icra eden üzerinde *cebir* veya *tehdit* tatbikidir. Gerçi, bu durumda cebir veya tehdit tatbik edilen ön plandaki şahıs fiilin icra edilişi üzerindeki hakimiyeti kendi elinde tutmaktadır. Fakat, arka plandaki şahsın irade hakimiyeti ona fiil üzerinde hakimiyeti sağlamaktadır¹¹⁵⁴.

Bir başkasını suçun işlenişinde araç olarak kullanan kişi, suçun faili olarak cezalandırılacaktır. Ancak, kusur yeteneği olmayanların suçun işlenmesinde araç olarak

Moderne Wege, 32; SCHMIDHAEUSER, Lb., 14/30, 31; ROXIN, Täterschaft, 2. bası (1967), sh. 531 vd.

¹¹⁵⁴ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 197 vd.; ÖNOK, Müşterek Suç Girişimi, sh. 221 vd.

kullanılması halinde, dolaylı faile verilecek cezanın artırılması öngörülmüştür. Bu artırma, 61. maddenin beşinci fıkrasındaki sıra çerçevesinde yapılacaktır. Keza, işaret etmek gerekir ki, bu artırma ancak süreli hapis cezası bakımından mümkündür. Bu nedenle, kişiye verilecek cezanın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması durumunda, bu cezalarda artırma yapılamayacaktır. Söz konusu maddenin TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında bu durumu gündeme getirmemize rağmen; bu uyarımız, Komisyon üyesi Milletvekilleri ve Komisyon toplantılarına katılan Yargıtay temsilcileri tarafından dikkate alınmamıştır.

Kanaatimizce, suçun kanunî tarifindeki fiili bizzat gerçekleştirmediği halde, bir başkasını suçun işlenişinde vasıta olarak kullanması dolayısıyla, arka plandaki şahsı *fail* olarak sorumlu tutmamızın yanı sıra, ayrıca bu nedenle cezasında bir artırım cihetine gidilmesinin ceza siyaseti açısından izahı güçtür¹¹⁵⁵.

¹¹⁵⁵ Yargıtay 13. Ceza Dairesi'nin **29.4.2015** tarihli ve E. 2014/22255, K. 2015/8049 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda A, henüz 12 yaşını doldurmamış olan oğlu B ile birlikte, bir alışveriş merkezindeki kafeteryada hırsızlık yapar. A “perdeleme” görevi yaparken, B sandalyenin koluna asılı bulunan bir başkasına ait çantayı aşırır.

Bu olayda Esas Mahkemesi hırsızlık suçunun temel şeklinin (TCK, m. 141, f. 1) işlendiğini kabul etmiştir; buna karşılık 13.CD ise hırsızlık suçunun “*Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında*” işlendiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

Bu olayda muhafaza altına alınmış eşyadan söz edilemez. Bu nedenle Esas Mahkemesinin kabulü doğrudur.

Esas Mahkemesi ayrıca, çocuğunu hırsızlık suçunun işlemeye azmettirmiş olması dolayısıyla, TCK, m. 38, f. 2 hükmü gereği olarak A hakkında verilen cezayı 1/3 oranında artırmıştır.

13.CD ise, A'nın bu olayda dolaylı fail olduğunu, bu nedenle hakkında belirlenen cezanın TCK, m. 38, f. 2 hükmü gereği olarak değil, m. 37, f. 2 hükmü gereği olarak artırılması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

Bu olayda A, oğlu B'yi sadece yönlendirmekle yetinmemiş, fiilin icrası sırasında B üzerinde hakimiyet de tesis etmiştir. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine ya da davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğine sahip olmayan bir çocuk bakımından azmettirmeden değil, ancak yönlendirmeden söz edilebilir. Bu nedenle, 13. Ceza Dairesinin A'nın dolaylı fail olarak sorumlu tutulması gerektiği yönündeki içtihadı doğrudur.

A'nın B'yi hırsızlık suçunun işlenmesinde araç olarak kullanmış olduğunu kabul etmek ve bu bağlamda A'yı dolaylı fail olarak sorumlu tutmak gerekir. Ancak A, söz konusu suçun işlenmesi sırasında aynı zamanda “perdeleme” görevi yapmak suretiyle, fiilin icrasına da katılmıştır. Başka bir ifadeyle, A söz konusu hırsızlık suçunun icrasında aynı zamanda doğrudan fail olarak da görev almıştır. A'nın hırsızlık suçunun icrası sırasında görev üstlenmiş olması, bu suçun işlenmesinde çocuğu (B'yi) araç olarak kullanmış olması dolayısıyla, hakkında verilen cezanın TCK, m. 37, f. 2 hükmüne istinaden artırılmasına engel teşkil etmez. Bu itibarla da, 13. Ceza Dairesinin söz konusu kararı doğrudur.

Çocuk olmasına rağmen failin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine ve ayrıca davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğine sahip olması halinde, A'nın azmettirmesinden söz etmek mümkün olurdu. Üçüncü yaş grubuna giren çocukları bu çerçevede düşünmek gerekir. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken husus, çocuğun cebir, tehdit veya hile gibi sair bir sebeple araç durumuna irca edilmiş olup olmamasıdır.

765 s. TCK’da dolaylı faillik konusunda bir hüküm bulunmamaktadır¹¹⁵⁶.

Karara konu teşkil eden olayda ise çocuk (B) henüz 12 yaşını doldurmamıştır. Kendisini suç işlemeye sevk eden babasıdır. Babasının yönlendirmesi altında bulunan bu çocuğun işlenen suç bağlamında araç durumuna irca edilmiş olduğunda kuşku yoktur. Bu olayda azmettiren-azmettirilen ilişkisinden söz edilemez.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi ise, benzer bir olayda farklı yönde içtihatla bulunmuştur (04.12.2014, E. 2012/23727, K. 2014/21476). Karara konu teşkil eden olayda C, 12 yaşını doldurmuş olmakla birlikte henüz 15 yaşını tamamlamamış olan kardeşi D ile birlikte hırsızlık yaparlar. Kararda bu olay bakımından D’nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayacak olgunluğa henüz ulaşmadığı kabul edilmiştir. Bu olayda, C gözcülük yapar, D de park halinde ve kapısı kilitli olan aracın kapısını açarak teybini alır.

Daire bu olayda, A’nın dolaylı fail değil, “doğrudan” fail olduğunu kabul eder. Daire’nin bu kabulüne göre, A’nın “doğrudan” fail olarak sorumlu tutulabileceği bir durumda, hakkında verilen ceza TCK, m. 37, f. 2 hükmüne istinaden artırılmaz.

Şayet D’nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmediği kabul edilmiş ise, bu durumda, C bakımından artık azmettirmeden değil, dolaylı faillikten söz etmek gerekir. Bu durumda C’nin D’yi hırsızlık suçunun işlenmesinde araç olarak kullanmış olduğunu kabul etmek ve bu bağlamda C’yi dolaylı fail olarak sorumlu tutmak gerekir. Ancak C, söz konusu suçun işlenmesi sırasında aynı zamanda gözcülük yapmak suretiyle, fiilin icrası sırasında fiilen görev yapmıştır. Başka bir ifadeyle, C söz konusu hırsızlık suçunun icrasında aynı zamanda doğrudan fail olarak da görev almıştır. C’nin fiilin icrası sırasında görev üstlenmiş olması, bu suçun işlenmesinde çocuğu (D’yi) araç olarak kullanmış olması dolayısıyla, hakkında verilen cezanın TCK, m. 37, f. 2 hükmüne istinaden artırılmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle, 6. Ceza Dairesinin söz konusu kararını doğru bulmamaktayız.

Ayrıca belirtelim ki, 6. Ceza Dairesinin kararına konu teşkil eden olayda, C, gözcülük yapmıştır. D ise, kapısı kilitli olan park halindeki aracın kapısını açarak teybini almıştır. Kapısı kilitli olan başkasına ait aracın kapısının çeşitli teknikler kullanarak açılmasını sağlayabilecek marifeti gösteren bir kişinin, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin olmadığı yönündeki kabulde bir sorun olduğunu düşünmekteyiz. Bu olay bakımından ancak D’nin ağabeyi C tarafından sevk ve idare edilerek, yani yönlendirilerek hırsızlık suçunun işlenmesinde araç olarak kullanılmasından söz edilebilir. Böyle bir durumda, suçun işlenmesi, D’nin inisiyatifine havale edilmemiştir; C suçun işlenmesi sürecine başından sonuna kadar vaziyet etmiştir. Başka bir ifadeyle, bu olayda, D’nin, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahip olmasına rağmen, ancak ağabeyi C’nin üzerinde tesis ettiği hakimiyet dolayısıyla davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğinin ortadan kalkmış olmasından söz edilebilir. Ancak, 6. Ceza Dairesi, benzer bir olayda açıklamalarınıza uygun yönde içtihatla bulunmuştur. Dairenin 24.06.2014 tarihli ve E. 2012/6508, K. 2014/13105 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda Erdal ve Songül, çalıntı plakalı bir araçla müşterinin fidan satışı yapan işyerine gelirler; yanlarında da 12 yaşından küçük olan Sami’yi getirirler. Erdal ve Songül, dışarıda beklerken, Sami’yi müşterinin işyerine gönderirler. Sami, kendisine verilen talimat doğrultusunda, müşteriye dışarıda bekleyenlerin anne ve babası olduğunu ve fidan bakacaklarını söyler. Bunun üzerine dışarı çıkan müşteri, fidan fiyatlarını soran Erdal ve Songül ile meşgul olurken, Sami, işyerinde masa üzerinde duran müşteriye ait cep telefonunu çalar.

Daire bu olayda Erdal ve Songül’ün hırsızlık suçunun işlenmesinde kusur yeteneği olmayan yaşı küçük Sami’yi araç olarak kullandıklarını kabul ederek, haklarında verilen cezanın TCK’nın 37. maddesinin ikinci fıkrası hüküm gereğince artırılması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

¹¹⁵⁶ Buna karşılık, Yeni TCK’na ilişkin Hükümet Tasarısının “*dolayısıyla faillik*” başlığını taşıyan 41. maddesinde bu konuya ilişkin müstakil bir hükme yer verilmiştir. Ancak, bu hükümde do-

II. Şeriklik

A. Azmettirme

Suçlar kural olarak, bir kişi tarafından tek başına işlenebileceği gibi, birden fazla kişinin iştirakiyle de işlenebilirler. Bir suçun icrasına iştirak eden suç ortaklarının bu suçun işlenişine bulundukları katkıları göz önünde bulundurularak *sorumluluk statüleri* belirlenmektedir.

İştirak şekilleri genel bir şekilde **faillik** ve **şeriklik** olarak ikiye ayrılmaktadır¹¹⁵⁷. Bu sorumluluk şekillerinden faillik, kanunda tarif edilmiş haksızlığın gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Böylece, belli bir neticenin oluşumuna illî etkide bulunan herkes değil, ancak kanunda tarif edilen muayyen haksızlığı gerçekleştiren suç ortağı/ortakları *fail* olabilecektir.

Suçun icrasına iştirak etmekle beraber, suçun işlenişine bulunduğu katkı suçun kanundaki tarifine uygun olmayan diğer suç ortaklarının da gerçekleşen haksızlık-tan sorumlu tutulabilmeleri gerekir. Suçun işlenişine bulunduğu katkı kanunî tarifteki haksızlığı gerçekleştirmeyen diğer suç ortakları, **şerik** olarak nitelendiril-

laylı failliğin alanı oldukça daraltılmıştır. Buna göre, suçun kanunî tarifindeki maddi unsurları gerçekleştiren şahsın a) “isnat yeteneği”ne sahip olmaması veya b) kişisel nedenlerle cezaen sorumlu tutulmaması gerekir ki, dolaylı faillikten bahsedilebilsin.

Önce belirtmemiz gerekir ki; fiilin işlenişine katkıda bulunan kişinin münhasıran “isnat yeteneği”nin olmaması, diğer suç ortağının dolaylı fail olmasını gerektirmez. Dolaylı faillik için, “isnat yeteneği”ni haiz olmayan kişi ve işlediği fiil üzerinde hakimiyet kurmak gerekir. Bir başka ifadeyle, “isnat yeteneği” olmayan kişi, suçun işlenişini açısından soyut bir araç durumuna irca edilmelidir.

Maddede dolaylı faillik için öngörülen ikinci ihtimal, kanunî tarife uygun fiili gerçekleştiren şahıs açısından *şahsi cezasızlık sebeplerinden* birinin mevcut olması halidir. Ancak, ifade edelim ki, bu durumda dolaylı faillik olmaz. Çünkü, kanunî tarife uygun fiili gerçekleştiren şahıs açısından bir şahsi cezasızlık sebebinin bulunması, arka plandaki kişinin fiilin işlenişini üzerinde hakimiyet kurmasını sağlayan bir husus değildir. İster *katı* ister *sınırlı bağlılık prensibi* benimsenmiş olsun; bu durumda fail-şerik ayırımına ilişkin genel hükümler uygulanmalıdır.

Ayrıca, madde hükmüne göre, bu kişilere “*her ne şekilde olursa olsun*” suç işletilmesi, dolaylı fail olarak sorumluluğu gerekli kılmaktadır. Dikkat edilmelidir ki; arka plandaki şahsın dolaylı fail olarak sorumlu tutulabilmesi için, suçun kanunî tarifine uygun fiili gerçekleştiren şahsın ve gerçekleştirdiği fiilin işlenişini üzerinde hakimiyet kurması gerekir; yani, ön plandaki şahıs, soyut bir araç durumuna irca edilmelidir. Bu “*her ne şekilde olursa olsun*” ifadesi ile, belki yanlışya sevk etmek ya da cebir veya tehdit kullanmak gibi ihtimaller kastedilmiş olabilir. Ancak, böyle de olsa; bu ifade, anlam yönünden bir kargaşaya sebebiyet verebilecek nitelikteydi. Bu itibarla, söz konusu madde metni, TBMM Adalet Komisyonunda yeni TCK’na ilişkin çalışmalar sırasında değiştirilmiştir.

Hükümet Tasarısının madde gerekçesinde “*dolayısıyla fail*” olan kişinin “*asli fail olarak cezalandırılması*” gerektiği belirtilmiştir. Ancak, ilginçtir ki, maddede sözü edilen bu iki halde, “*dolayısıyla fail*” olan kişilere verilecek ceza, “*suçun cezası üçte bire kadar arttırılır*” mak suretiyle tayin edilmektedir. Bu durumdaki “*kişilerce suçun işlenmesinin kolayca sağlanabileceği*” hususu, cezadaki bu artırımın gerekçesi olarak gösterilmiştir.

¹¹⁵⁷ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 139 vd.

mekte ve kanunun şerikliğe ilişkin genel hükümleri, **sorumluluk alanını genişleten hükümler** olarak telâkki edilmektedir. **Azmettirme** ve **yardım etme** olarak iki farklı tezahür şeklinin söz konusu olduğu şeriklikte, suç ortaklarının gerçekleştirilen kanunî tarife uygun haksızlıktan sorumlu tutulabilmeleri ancak **bağlılık kuralı** vasıtasıyla mümkün olabilecektir. Fail, gerçekleşen kanunî tarife uygun haksızlıkla, suçun objesiyle doğrudan temas halinde iken; şerik için böyle bir doğrudan temas söz konusu değildir. Şerik, faille olan şahsi bağlantısı nedeniyle ve ancak *bağlılık kuralı* vasıtasıyla söz konusu haksızlıktan sorumlu tutulacaktır¹¹⁵⁸.

Ancak, belirtmemiz gerekir ki; 765 s. TCK'da, azmettirme bir “*asli iştirak*” şekli olarak tavsif edilmiştir (m. 64, f. 2)¹¹⁵⁹. Bu şekildeki nitelendirmenin sebebi, azmettirenin fail gibi cezalandırılmasıdır.

Her ne kadar Kanunda, “*başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.*” şeklinde bir hükme yer verilmiş (m. 38, f. 1) olması itibarıyla 765 s. TCK'nın düzenlemesiyle bir paralelliği var ise de; Yeni TCK'da azmettirme bir *şeriklik türü* olarak düzenlenmiştir.

Azmettirme, belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan ve dolayısıyla karar vermemiş olan bir kişinin bir başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesidir¹¹⁶⁰. Dolayısıyla, ancak *kasten* işlenen bir suça azmettirme mümkündür. Azmettirme, daima fiil üzerinde manevi bir etkiyi ifade etmektedir. Genellikle kabul edildiği veçhile; ihmalî davranışla azmettirme mümkün değildir¹¹⁶¹.

Azmettirenin kasten hareket etmesi gerekir. Bu kastın, failde belli bir suçu işleme hususunda karar oluşturmayı, suçun bu kişi tarafından işlenmesi hususunu, azmettirilen suçun kanunî tarifindeki unsurlarını kapsamaması gerekir. Azmettirenin kastının müşahhas olması gerekir; yani, kişi, belli bir fiili işlemeye azmetti-

¹¹⁵⁸ Kavram hakkında bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 141 vd., 316.

¹¹⁵⁹ Aynı şekilde Tasarı, m. 40, f. 3; '89 ve '97 Öntasarıları, m. 38.

¹¹⁶⁰ “5237 s. TCK, 765 s. Yasada öngörülen “*asli iştirak-fer'i iştirak*” ayrımını terk ederek, yeni sistemde birer sorumluluk statüsü olarak öngörülen iştirak şekillerini, fiilin işleniş üzerinde kurulan hâkimiyet ölçü olarak alınmak suretiyle, faillik (37. md), azmettirme (38. md) ve yardım etme (39. md) olarak belirlemiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasasında benimsenen yeni suç teorisine göre azmettiren “fail” değil “şerik” konumundadır. Azmettirme, belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan kişide, bir başkası tarafından suç işleme kararının oluşmasının sağlanmasıdır. Eğer kişi daha önce suçu işlemeye karar vermiş ise, bu takdirde azmettirme olmaz, artık manevi yardım olabilir. Azmettirenin kasten hareket etmesi gerekir. Bu kastın, failde belli bir suçu işleme hususunda karar oluşturmayı, suçun bu kişi tarafından işlenmesi hususunu ve azmettirilen suçun kanuni tanımındaki unsurlarını kapsamaması gerekir. Eylemin yer ve zamanının veya eylemin işleniş tarzına ilişkin ayrıntıların belirlenmesine gerek yoktur.”: CGK, 16.2.2010, 2009/1-251, 2010/25.

Azmettirme konusunda bilgi için bkz. ÖZKAN, Halid: *Ceza Hukukunda Azmettirme*, Ankara 2013.

¹¹⁶¹ JESCHECK(4) sh. 626, dn. 32; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 506. Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku(2), sh. 239 vd.

rilmelidir ve bu fiilin belli bir şahsa yönelik olması gerekir. Ancak, fiilin işleneceği zaman ve yerin tayinine gerek yoktur. Azmettirme, bir fiilin esaslı unsurlarıyla veya ana hatlarıyla somutlaştırılmış olmasını zorunlu ve yeterli kılar. Bu itibarla, suçun icra tarzına ilişkin ayrıntıların belirlenmesine gerek yoktur¹¹⁶². Keza, belli bir kişi suç işlemeye azmettirilmelidir. Suç işlemesi istenen kişinin belli olmaması halinde, artık azmettirmeden bahsedilemez. Bu durumda, -diğer şartların gerçekleşmesi kaydıyla- suç işlemeye tahrik suçu (m. 214) söz konusu olur.

Azmettiren, azmettirilen kişide suçun işlenmesi konusunda karar oluşturmalıdır. Şayet kişi daha önce suçu işlemeye karar vermiş ise (omnimodo facturus); bu durumda azmettirmeye teşebbüs edilmiş veya suçun işlenmesine manevi yardımda bulunulmuş olur.

Kanunumuzun kabul ettiği (m. 40) bağlılık kuralına göre, her suç ortağının ancak kendi kusurundan dolayı sorumluluğu cihetine gidilebilecek, esas fiil failinin kusursuz oluşu şeriklerin statüsünde bir değişiklik meydana getirmeyecektir¹¹⁶³. Bu nedenle, meselâ, yaş küçüklüğü veya akıl hastalığı nedeniyle kusur yeteneği olmayan ya da bir mazeret sebebinin etkisindeki bir şahsın suç işlemeye azmettirilmesi halinde, *faili kusursuz olan esas fiile* şerik olarak iştirak edilebilecektir. Ancak, bu ihtimallerde, şerikliğe nazaran failliğin önceliği prensibi gereğince, azmettiren veya yardım edenin fiil üzerinde hâkimiyeti mevcutsa, meselâ kusur yeteneği olmayan birisinin bu halinden istifadeyle ya da cebir veya tehdit kullanılması sonucu kişinin mazur duruma düşürülmesiyle suça sevkedilmesi halinde, şekli olarak şerikliğinin (azmettirme) varlığı söylenebilir de; esas itibarıyla ortada bir şahsın suiistimal edilmesi ve buna bağlı olarak da (dolaylı) faillik sözkonusudur¹¹⁶⁴. Dolaylı fail, vakıaları başından sonuna kadar kendi kontrolünde bulundurmaktadır. Böylece dolaylı faillikte kişilerden birisi diğerinin vasıtası durumundadır; ortada **süje - obje ilişkisi** mevcuttur¹¹⁶⁵. Azmettirmede ise, serbest iradesiyle hareket eden bir şahsın korrupte, tefessüh ettirilmesi mevzubahistir. Azmettiren şahıs, suç işleme doğrultusundaki iradesini bir başkasına intikal ettirmektedir. Ancak, bu durumda, suçun işlenip işlenmeyeceği hususundaki kararın oluşumunda azmettiren azmettirilene tâbi olmaktadır¹¹⁶⁶. Böylece, azmettirenle azmettirilen arasında **şahsi bir ilişki** teşekkül etmektedir¹¹⁶⁷. Bir fiile şerik olarak iştirak edebilmek için, söz konusu fiilin en

¹¹⁶² JESCHECK(4), sh.623, dn. 19; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 484, 506.

¹¹⁶³ Ayrıntılı bilgi için bkz. BOCKELMANN, Täterschaft und Teilnahme, 1 vd.

¹¹⁶⁴ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 262, 265, 276 vd.; JESCHECK, Lb., 591, 601; BAUMANN/WEBER, 548; CRAMER, Schönke/Schröder, § 25 kn. 23.

¹¹⁶⁵ BLOY, 345.

¹¹⁶⁶ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 260/261; ÖNDER, Genel Hükümler II, 507.

¹¹⁶⁷ KOHLRAUSCH/LANGE, StGB, 175; BLOY, 345.

azından **kasten ve hukuka aykırı** olarak işlenmesi gerekir. Maddi ve manevi unsurların ve aynı zamanda hukuka aykırılığın gerçekleşmediği bir fiile şerik olarak iştirak mümkün değildir¹¹⁶⁸.

İzlenen suç siyaseti gereği olarak, azmettirenin suçun kanundaki cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir.

Ancak, dolaylı faillikte olduğu gibi, yeni TCK'da belli koşulların varlığı halinde azmettirenin cezasında artırım yapılması öngörülmüştür (m. 38, f. 2):

“Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi hâlinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz.”

Bu artırma, 61. maddenin beşinci fıkrasındaki sıra çerçevesinde yapılacaktır. Keza, işaret etmek gerekir ki, bu artırma ancak süreli hapis cezası bakımından mümkündür. Bu nedenle, kişiye verilecek cezanın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması durumunda, bu cezalarda artırma yapılamayacaktır. Söz konusu maddenin TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında bu durumu gündeme getirmemize rağmen; bu uyarımız, Komisyon üyesi Milletvekilleri ve Komisyon toplantılarına katılan Yargıtay temsilcileri tarafından dikkate alınmamıştır.

Kanaatimizce, azmettirenin suçun kanundaki cezası ile cezalandırdıktan sonra ayrıca belirtilen durumlarda cezasında artırım yapılmasının ceza siyaseti açısından izahı güçtür.

765 s. TCK'ya göre, “*fiili icra edenin onu işlemekte şahsi bir menfaati olduğu sabit olursa azmettiren şahsın cezası*”nda indirim yapılması gerekmektedir (m. 64, f. 2). Yeni TCK'da ise, bu durumla ilgili olarak bir hükme yer verilmemiştir.

Buna karşılık, yeni TCK'da, ayrıca “*Azmettirenin belli olmaması hâlinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. Diğer hâllerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir.*” şeklinde bir hükme yer verilmiştir (m. 38, f. 3).

Bu hüküm, **cezada indirim yapılmasını gerektiren bir şahsi sebebe** ilişkin bir düzenleme niteliği taşımaktadır. İşaret etmek gerekir ki, bu husus, iştirak ilişkisinde suç ortaklarının sorumluluk statüsüyle alakalı değildir. Her ne kadar az-

¹¹⁶⁸ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 261; BAUMANN, Beiträge, 212, 213, 214, 219, 221; CRAMER, Schönke/Schröder, § 25 kn. 26. Dolaylı faillikle azmettirme arasında sübjektif bir perspektifle yapılan bir ayırım için bkz. MEZGER, Moderne Wege, 29, 30 dn. 2, 3, 4; aynı yazar, LK(8), § 48 kn.1, 2b, 3d.

mettirme bağlamında yer alan bir hüküm ise de; bu husus, 61. maddenin beşinci fıkrasında söz konusu edilen cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler bağlamında değerlendirilmelidir¹¹⁶⁹.

Kanaatimizce özel faillik niteliğini taşımayan kişinin (extraneus) bu niteliği taşıyan bir şahsı (intraneus) özgü suçu işlemeye azmettirmesi halinde; hakime azmettirenin cezasında takdiri indirim yapma imkânının tanınması gerekir¹¹⁷⁰. Söz konusu maddenin TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında Kanuna bu yönde bir hüküm konulması hususunda öneride bulunmamıza rağmen, bu önerimiz kabul görmemiştir.

Azmettirilen fiilin tamamlanmış veya en azından teşebbüs aşamasında kalmış olması gerekir. Azmettirilen fiilin kasten işlenebilen bir suç olması gerekir. Bu fiilin işlenmesine teşebbüs dahi edilmemiş ise, **akim (neticesiz, sonuçsuz) kalmış azmettirmeden** bahsedilir. Akim kalmış azmettirme halinde, azmettirenin cezalandırılacağına dair Kanunda genel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu durumda azmettirene prensip olarak ceza verilemeyeceği kabul edilmektedir¹¹⁷¹. Ancak, kanunda belli bir suça azmettirmenin bağımsız bir suç olarak tanımlandığı durumlarda, azmettirme akim kalmış olsa bile, azmettiren (fail) cezalandırılacaktır. Meselâ, 765 s. TCK’da yalan şahitlik, bilirkişilik ve tercümanlık suçuna azmettirme, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştı (m. 291). Dikkat edilmelidir ki, bu 291. maddede tanımlanan suçun tamamlanmış olabilmesi için failin “*yalan şahadetini işletmiş ve(ya) hilâfi vâki rey beyan ve tercümanlık ifa ettirmiş*” olması gerekmektedir. Şayet, azmettirmeye rağmen, azmettirilen kimse yalan şahitlikte bulunmamış, gerçeğe aykırı görüş beyan veya tercümanlık etmemiş ise; kanaatimizce, suç teşebbüs derecesinde kalmıştır. Bu durumda azmettiren (fail), ancak bu suça teşebbüsten dolayı cezalandırılabilir.

Yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısında da “fiili işlediği takdirde” ifadesine yer verilmek (m. 40, f. 2) suretiyle akim kalmış azmettirme halinde azmettirenin prensip olarak cezalandırılmayacağı kabul edilmiştir¹¹⁷².

Kanaatimizce akim kalmış azmettirme halinde azmettirenin belli bir oranda cezalandırılabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanıyan bir hükmün Kanuna konmasında fayda vardır. Ancak, Yeni TCK’ya ilişkin olarak TBMM Adalet Komisyonunda yapılan çalışmalar sırasında, Kanuna bu yönde bir hüküm konulması hususunda girişimde bulunmamıza rağmen, bu girişimimizden olumlu

¹¹⁶⁹ Bayraktar’a göre “*bu düzenleme ile ‘sayın muhbir vatandaş’ kavramı geri dönmektedir.*” (BAYRAKTAR, Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Genel Bir Değerlendirme ve Genel Hükümler Üzerine Birkaç Eleştiri, sh. 33). Bu değerlendirme, yeni TCK’ya yöneltlen bazı eleştirilerin bilimsel bakımdan sığılığı ile ilgili bir örnektir.

¹¹⁷⁰ JESCHECK(4), sh. 624, dn. 23.

¹¹⁷¹ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1220, 1232.

¹¹⁷² ’89 ve ’97 Öntasarıları, m. 38, f. 2.

sonuç alınamamıştır. Hatta, hiç olmazsa yalan tanıklık suçunun tanımlandığı 272. maddeye bu hususta bir hüküm konulması yönündeki önerimiz de kabul görmemiştir.

Bu önerimiz, aslında **niceliksel bağlılık kuralı**yla çelişmemektedir. Yeni TCK'nın 40. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; “*Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için, ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir.*” Şeriklik halleri haksızlık içeriklerini failin işlediği fiilden aldığına göre, bu fiilin en azından icrasına başlanmalıdır ki, iştirak hükümlerine göre cezalandırma yoluna gidilebilsin. Ancak, belirtmek gerekir ki, azmettirme halinde, azmettirme fiili de başlı başına bir haksızlık ifade etmektedir. Azmettirmede, serbest iradesiyle hareket eden bir şahsın korrupte edilmesi, tefessüh ettirilmesi söz konusudur; yani suç işlemeyi aklının köşesinden dahi geçirmeyen bir kişide suç işleme yönünde bir karar oluşturulması sağlanmaktadır. Bu nedenle, esas fiilin icrasına henüz başlanmamış olsa da, azmettirme olgusu başlı başına bir haksızlık ifade etmektedir. Nitekim, bu husus, madde gerekçesinin ikinci paragrafında açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Azmettirilenin sınırı aşması halinde; önemsiz sapmalar, işlenen suçtan dolayı kişinin azmettiren sıfatıyla sorumlu tutulmasına engel teşkil etmez.

Azmettirilen, azmettirildiği suçun sınırını keyfiyet itibarıyla aşmış olabilir. İşlenen suç, azmettirilen suça nazaran daha hafif cezayı gerektiren bir suç olabilir. Bu durumda azmettirenin gerçekleşen suçtan dolayı sorumlu tutulabilmesi için, azmettirilen suçla işlenen suçun aynı nitelikte olması gerekir¹¹⁷³.

İşlenen suç, azmettirilen suça nazaran daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç olabilir. Meselâ hırsızlık suçunu işlemek için azmettirilen kişi yağma veya cinsel saldırı suçunu işlemiş olabilir. Böyle bir durumda işlenen bu suçlardan dolayı hırsızlık suçuna azmettireni sorumlu tutmamak gerekir¹¹⁷⁴.

Azmettirilen suçun sınırı kemiyet itibarıyla da aşılmış olabilir. Meselâ kasten yaralamanın temel şekline azmettirilen kişi, mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine sebebiyet vermek gibi, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halini gerçekleştirmiş olabilir. Azmettiren, bilgisi dışında sınır aşıldığı için, ancak azmettirdiği fiilden dolayı sorumlu olacaktır¹¹⁷⁵. Azmettirme sınırının aşılmış olmasından dolayı sadece fiili işleyen sorumlu tutulabilecektir. Ancak, vermiş bulunduğumuz örnekte kasten yaralama suçunun temel şeklini işleme konusunda azmettirilen kişinin bu suçun nitelikli halini işleyebileceği pekala muhtemel addedilebilir. Bu durumda suçun nitelikli halinin

¹¹⁷³ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 494.

¹¹⁷⁴ DÖNMEZER/ERMAN II, no 1246,; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 493.

¹¹⁷⁵ Vukuf şartını araması itibarıyla bkz. DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1242, 1284.

işlenmesi hususunda azmettirenin (olası, muhtemel) kastının var olduğunu söylemek gerekir¹¹⁷⁶.

Azmettirilen, suçun konusunda veya mağdurun kimliğinde hataya düşmüş olabilir ve hatta, hedefte sapma neticesinde suçu bir başkası aleyhine işlemiş olabilir. Bu durumda meselenin suçun konusunda veya mağdurun kimliğinde hata ya da hedefte sapma hükümlerine göre çözümleneceği açıktır¹¹⁷⁷.

Azmettirme, bir kişi tarafından yapılabileceği gibi, birden fazla kişi tarafından müştereken de yapılabilir. Hatta, birden fazla kişi, birbirinden habersiz olarak bir kişiyi belli bir suçu işlemeye azmettirmiş olabilir.

Azmettirmeye azmettirme de mümkündür. Bu durumda, aradaki azmettiren(ler)in veya esas fiil failinin kimliği konusunda bilgi sahibi olunması gerekmez. Fakat, işlenecek suç açısından azmettiren(ler)in düşüncesinin somutlaşması gerekir¹¹⁷⁸.

B. Yardım Etme

Yardım etme, bir başkasının kasten işlemekte olduğu bir suçun icrasının kasten desteklenmesini ifade etmektedir. Failin, suç teşkil eden fiili işlerken, bir başkası tarafından desteklendiğinin, kendisine yardım edildiğinin bilincinde olmasına gerek yoktur^{1179,1180}.

Bir suçun işlenmesine yardımda bulunma maddi ve manevi olmak üzere iki tarzda mümkündür.

Manevi yardım, failin suç işleme doğrultusundaki kararını kuvvetlendirmekten, takviye etmekten ibarettir. Bu kapsamdaki yardımı geniş yorumlamak gerekir. Şöyle ki, meselâ suçun işlenmesinde kullanması için faile verilen bir aracın bilahare fail tarafından kullanılmaması halinde de; bu aracın faile temini ondaki suç işleme kararını takviye ettiği için, kişi yine şerik (yardım eden) olarak sorumlu

¹¹⁷⁶ *Dönmezer/Erman ve Önder*, bu durumda meselenin netice sebebiyle ağırlaşmış suçlara ilişkin hükümler çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği fikrindedirler (DÖNMEZER/ERMAN II, no 1246; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 493/494).

¹¹⁷⁷ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1247.

¹¹⁷⁸ Bu hususta bilgi için bkz. DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1291.

¹¹⁷⁹ ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku(2), sh. 242. Nitekim *Dönmezer/Erman* da, iştirak iradesinin mevcudiyetini aramakla beraber; failin suç teşkil eden fiili işlerken bir başkasının kendisine yardım ettiğinden haberdar olmamasına rağmen, yardımda bulunanın şerik olarak sorumlu tutulması gerektiği fikrindedirler (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1236).

¹¹⁸⁰ Nitekim, yeni TCK'nın 37. maddesinin gerekçesinde, “Bir suçun failine, onun haberi olmaksızın, tek taraflı iradeyle, suçun işlenmesine başlamadan önce veya suçun icrası sırasında yardım edilmesi hâlinde, müşterek fail olarak değil, yardım eden olarak sorumlu tutulmak gerekir.” denilmek suretiyle bu hususa işaret edilmiştir (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 444 vd.).

tutulacaktır¹¹⁸¹. Manevi yardımda bulunma halleri, 39. maddede şu şekilde tasrih edilmiştir: a) *suç işlemeye teşvik etmek* (m. 39, f. 2, bent a), b) *suç işleme kararını kuvvetlendirmek* (m. 39, f. 2, bent a), c) *suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaat etmek* (m. 39, f. 2, bent a) ve d) *suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek* (m. 39, f. 2, bent b). Manevi yardımda bulunma halleri doktrin ve uygulamamızda “fer’î manevi faillik” ya da “fer’î manevi iştirak” olarak ifade edilmektedir.

Bir suçun işlenmesine **maddi yardım** da çok çeşitli şekillerde tezahür edebilir. 39. maddede,

a) *suçun işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak* (m. 39, f. 2, bent b),

b) *suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında (maddi) yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak* (m. 39, f. 2, bent c),

suçun işlenmesinde maddi yardımda bulunma halleri olarak gösterilmiştir. Maddi yardımda bulunma halleri de doktrin ve uygulamamızda “fer’î maddi faillik” ya da “fer’î maddi iştirak” olarak ifade edilmektedir.

Bir başkasının işlediği suça bulunulan yardımın meydana gelen neticeyle illi bağlantı içinde bulunması gerekir¹¹⁸².

Bu bağlamda, **bir başkasının icrai suçuna ihmali davranışla iştirak** halinde sorumluluk konusuna açıklık getirmek gerekir.

Belli bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi suretiyle de, başkası tarafından icraî davranışla işlenen bir suçun işlenmesine iştirak edilmiş olabilir. Başka bir ifadeyle, **bir başkasının işlemekte olduğu suçun işlenişine engel olmama halinde, bu icraî suça yardımda bulunma** söz konusu olacaktır¹¹⁸³. Örneğin, baba 15 yaşındaki çocuğunu eve hapseder. Çocuk, aylarca evden dışarı çıkamaz. Anne, bu durumdan haberdardır ve çocuğun bu durumdan kurtarılması için herhangi bir girişimde bulunmaz. Baba gibi annenin de çocuk üzerinde velayet ilişkisinden kaynaklanan **bakım ve gözetim yükümlülüğü** bulunmaktadır (Bkz. 22.11.2001 t. ve 4721 s. Türk Medeni Kanunu, m. 335 vd.). Bu bakım ve gözetim yükümlülüğü, **çocuğa karşı işlenmekte olan bir suçun işlenmesini önleme yükümlülüğü**nü de ifade etmektedir. Bu itibarla annenin, baba tarafından çocuğuna karşı **işlenmekte olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu-na** (TCK, m. 109) ihmali davranışla **iştirak**ten dolayı yardım eden sıfatıyla so-

¹¹⁸¹ JESCHECK(4), sh. 626, dn.34, sh. 627/628; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 511.

¹¹⁸² *Dönmezer/Erman*, zehirlemek suretiyle adam öldürmeyi planlayan kişinin bu amaçla kendisine zehir temin edilmesinden sonra fikir değiştirerek mağduru bıçakla yaralamak suretiyle öldürmesi halinde; zehir tedarikinin suçun işlenişine illi katkısının olmadığı fikrindedirler (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1231).

¹¹⁸³ JESCHECK (4), sh. 548, 618, 630, dn. 55

rumlu tutulması gerekir. Diğer bir örnekte, baba çocuğuna karşı müteselsilen cinsel istismarda bulunur. Anne, bu durumdan haberdardır ve çocuğun bu durumdan kurtarılması için herhangi bir girişimde bulunmaz. Bu durumda anne, babanın müteselsilen **işlemekte olduğu cinsel istismar suçuna** (TCK, m. 103) ihmali davranışla **iştirak** etmiştir. Keza, bankanın önceden soyulacağından haberdar olan güvenlik görevlisi (bekçi) tarafından, soyguncuların suçu işlemelelerini kolaylaştırmak amacıyla kapının açık bırakılması durumunda, güvenlik görevlisi, işlenen hırsızlık suçundan dolayı ancak yardım eden (şerik) sıfatıyla sorumlu tutulacaktır¹¹⁸⁴.

Ancak, ihmali davranışta bulunan kişi bakımından bu ihmali davranış kanunda müstakil bir suç olarak tanımlanmış ise, artık bir başkasının icraî davranışla işlemekte olduğu suça ihmali davranışla iştirak edilerek yardım eden (şerik) sıfatıyla sorumluluktan değil, **ihmali suçtan** dolayı **fail** sıfatıyla sorumluluk cihetine gitmek gerekir. Örneğin A B'ye karşı kasten öldürme veya kasten yaralama suçunu işlemektedir. Duruma muttali olan kolluk görevlileri olaya müdahale etmezler. TCK'da kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının ihmali davranışla işlenmesi, icraî suça nazaran müstakil bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu durum karşısında, işlenmekte olan suç olgusu ile karşı karşıya olan emniyet görevlisinin, önleme imkan ve iktidarına sahip olmasına rağmen, bu suçun işlenmesine engel olmaması halinde, kasten öldürme veya kasten yaralama suçunu ihmali davranışla işlemekten dolayı sorumlu tutulması gerekir. Aslında kolluk görevlisi bu ihmali davranış, bir başkasının işlemekte olduğu kasten öldürme veya kasten yaralama suçuna iştirakten dolayı yardım eden sıfatıyla da sorumluluğunu gerektirmektedir. Ancak, Kanunda kasten öldürme veya kasten yaralama suçlarının ihmali davranışla işlenmesi müstakil bir suç olarak tanımlandığı için (TCK, m. 83, 88), kolluk görevlisinin bu durumda sadece fail sıfatıyla sorumluluğunu gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması gerekir. Bu örnekte kişinin gerçekleştirdiği davranış, hem bir başkasının işlediği suça yardımda bulunmak dolayısıyla **şerik sıfatıyla sorumluluğu**, hem de ihmali davranışla işlenen suçun **faili olarak sorumluluğu** gerekli kılmaktadır. **Failin şerikliğe nazaran aslîliği** ilkesi gereğince bu durumda kişiyi sadece ihmali davranışla işlediği suçtan dolayı fail olarak cezalandırmak gerekecektir.

Yeni TCK'da işkence suçu ile bağlantılı olarak, “**bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.**” hükmüne yer verilmiştir (m. 94, f. 5). Madde **gereğince** bu hükümle ilgili olarak şu açıklamalar yer almaktadır:

“İşkence suçu, çoğu zaman, amir mevkiindeki kamu görevlilerinin zimni muvafakatiyle gerçekleştirilmektedir. Başka bir deyişle, amir konumundaki kamu görev-

¹¹⁸⁴ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suç Örgütleri (12), sh. 216, dn. 9.

*lisi, kendi gözetim yükümlülüğü altında yürütülmekte olan bir soruşturma işlemi sırasında kişilere işkence yapıldığını öngörmesine rağmen bu konuda gerekli müdahalede bulunmamak suretiyle işkence yapılmasına zımnen rıza göstermiş olabilir. Maddenin beşinci fıkrasına göre; bu gibi durumlarda, amir konumundaki kamu görevlisi, **ihmali davranışla işkence suçunu işlemiş** kabul edilecek ve bu nedenle cezasında indirim yapılmaksızın sorumlu tutulacaktır.*"¹¹⁸⁵.

Keza, yeni TCK'da "**zimet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.**" hükmüne yer verilmiştir (m. 251, f. 1). Madde gerekçesinde bu hükümle ilgili olarak şu açıklamalar yer almaktadır:

*"Madde metninde denetim görevinin ihmali, ceza yaptırımına bağlanmıştır. Birinci fıkra da zimet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman kamu görevlisinin, işlenen suçun **müşterek faili** olarak sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, kamu görevlisi, zimet veya irtikâp suçunun işlendiğinden haberdardır ve buna rağmen denetim görevini kasten ihmal etmektedir."*^{1186, 1187, 1188}.

¹¹⁸⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 500 vd.

¹¹⁸⁶ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 646 vd. Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Zimet Suçu*, 2. bası, Ankara, Temmuz 2012, sh. 107.

¹¹⁸⁷ Bingöl'ün Genç ilçesinde aile içerisinde onbeş yaşından küçük olan mağdureye karşı kardeşleri tarafından temadi eder biçimde cinsel istismar suçu işlenir. Anne, bu suçun işlenmekte olduğunu bilmesine rağmen, yetkili mercilere bildirimde bulunmaz. Cinsel istismar suçunu işleyen kardeşler hakkında dava açılmasının yanı sıra, anne hakkında da suçu bildirmeme suçundan dolayı TCK'nın 278. maddesinde tanımlanan suçu işlediğinden bahisle kamu davası açılır.

Görülmekte olan bu davada Cumhuriyet savcısı TCK'nın 278. maddesinde şahsi cezasızlık sebebine yer verilmemiş olması dolayısıyla, bu madde hükümlerinin Anayasanın 38. maddesinin beşinci fıkrası hükmüne aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Mahkeme, bu iddiayı ciddi bularak, itiraz yoluna başvurmuştur. İtiraz üzerine Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinde "**Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.**" ilkesine yer verildiği (f. 5) ve buna rağmen TCK'nın 278. maddesinde tanımlanan suçu bildirmeme suçu ile ilgili olarak söz konusu Kanunda "**yakın akrabalık durumu**"nu dikkate alan şahsi cezasızlık sebebine yer verilmediği gerekçesiyle, söz konusu madde hükmünün bütünüyle iptaline karar vermiştir: Anayasa Mahkemesi, 30.6.2011, Esas 2010/52, Karar 2011/113 (RG: 15 Ekim 2011/28085).

Anayasa Mahkemesinin kararının ilişkin olduğu olayda, kardeşler A ve B tarafından henüz 15 yaşını doldurmamış olan diğer kardeş C'ye karşı **müteselsilen işlenmekte olan bir cinsel istismar suçu** (TCK, m. 103) söz konusudur. Anne, bu durumdan haberdardır ve çocuğun bu durumdan kurtarılması için herhangi bir girişimde bulunmaz. Bu durumda anne, A ve B'nin müteselsilen **işlemekte olduğu cinsel istismar suçuna** (TCK, m. 103) ihmali davranışla **iştirak** etmiştir ve söz konusu suça yardım eden (şerik) sıfatıyla iştirakten dolayı sorumlu tutulmalıdır. Bu nedenle, söz konusu olayda annenin sorumluluğunun TCK'nın 278. maddesinde tanımlanan suçu bildirmeme suçu bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutulması doğru olmamıştır.

Buna karşılık, icrası devam etmekte olan bir suçla ilgili olarak kişinin suçu işlenmesini önleme yükümlülüğünün bulunmamasına rağmen bildirim yükümlülüğü söz konusu olabilir. Ör-

neğin, A, kaçak elektrik kullanmaktadır. Durumdan haberdar olan komşu B'nin, A'nın bu suç işlemesini önlemek için müdahalede bulunma yükümlülüğü yoktur. Ancak B, işlenmekte olan bu hırsızlık suçu ile ilgili olarak bildirim yükümlülüğü altındadır. B tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, TCK'nın 278. maddesinde tanımlanan suçu oluşturur (f. 1).

Baba ile oğlu, aynı apartmanın farklı dairelerinde otururlar. Oğul evine kaçak elektrik bağlar; baba, durumdan haberdar olmasına rağmen, bildirimde bulunmaz. Bu örnek olayda baba, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyi ihmal etmiştir. Ancak, baba ile oğlu arasındaki akrabalık (üstsoy-altsoy) ilişkisi, baba bakımından bir **şahsi cezasızlık sebebi** oluşturur.

Baba, üniversite öğrencisi olan oğlunun terör örgütü mensubu olduğunu bilir. Oğlu belirli aralıklarla dağa çıkarak örgütün eğitim programlarına katılır, örgüt tarafından verilen talimatları yerine getirir. Ancak, baba buna rağmen oğlu ile ilgili olarak bildirimde bulunmaz. Burada da, yukarıdaki elektrik hırsızlığı örneğinde olduğu gibi, baba hakkında suçu bildirmeme suçundan dolayı cezaya hükmetmemek gerekir.

TCK'nın 278. maddesinde tanımlanan suçu bildirmeme suçunun konusunu, **icrası tamamlanmış** olmakla birlikte, **sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan suç** da oluşturabilir.

İcrası tamamlanmış olan bir suç bağlamında bu suçun işlenmesini önleme yükümlülüğünden artık söz edilemez. Çünkü bu durumda artık suç işlenmiş ve tamamlanmıştır. İşlenmiş olan bir suçu işlenmemiş duruma irca etmek mümkün değildir.

Örneğin A hırsızlık suçundan elde etmiş bulunduğu bisikleti kullanmaya devam eder. Baba B, bu durumu öğrenir. Ancak, oğlu ile ilgili olarak hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle ihbarda bulunmaz.

İcrası tamamlanmış bir suçla ilgili olarak aile bireylerinin ve belirli bir akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişilerin ihbarda bulunmaması ile ilgili olarak Anayasa'nın 38. maddesinin beşinci fıkrası hükmü karşısında bir **şahsi cezasızlık sebebinin** bulunduğunu kabul etmek gerekir. Her ne kadar TCK'nın 278. maddesinde bu hususta bir hükme yer verilmemiş ise de, kanaatimizce bu gibi durumlarda mahkeme tarafından Anayasanın 38. maddesinin beşinci fıkrası hükmüne istinaden bildirimde bulunmayan kişi hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi mümkündür.

Ancak bu husus Anayasa Mahkemesi tarafından verilen söz konusu iptal kararında TCK'nın 278. maddesinde tanımlanan suç bağlamında bir "eksiklik" olarak telakki edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu eksikliğin giderilmesine yönelik bir düzenleme yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Fakat bu eksikliğin giderilmesi bağlamında yapılacak olan kanuni düzenlemenin işlenmekte olan suçu önleme yükümlülüğünün bulunduğu halleri kapsamına almaması gerekir. Bu itibarla, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen TCK'nın 278. maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra eklenerek, bu maddenin yeniden kanunlaştırılması gerekmektedir.

"Suçun, üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi hâlinde, cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır."

Nitekim, Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı üzerine, TCK'nın 278. maddesi, **2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla**, yeniden düzenlenmiş ve maddeye dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra eklenmiştir:

"Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır."

Bu düzenlemenin gerekçesi olarak 6352 sayılı Kanuna ilişkin Hükümet Tasarısında şu açıklamalara yer verilmiştir:

"Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi de göz önünde bulundurulmak suretiyle, ilk üç fıkrası aynen muhafaza edilerek, maddeye yeni bir fıkra eklenmiş ve bu suç bakımından da şahsi cezasızlık sebebinin varlığına yer verilmiştir. Bununla birlikte, maddenin birinci fıkrasındaki işlenmekte olan suçlar bağlamında bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi dolayısıyla ceza

Suçun işlenmesine bulunulan yardımın, en geç bu suçun unsurlarının gerçekleştirilişi sırasında yani tamamlanmadan önce yapılması gerekir. Yardım, hazırlık hareketlerine de ilişkin olabilir¹¹⁸⁹. Fakat, bu nedenle sorumluluk için, suçun icrasına en azından teşebbüs edilmiş olması gerekir.

Bir suçun işlenmesine yardımda bulunanın kasten hareket etmesi gerekir. Bir suçun icrasına taksirle yardımda bulunma cezalandırılmaz. Meğer ki bu fiil, ceza kanununda (taksirle işlenen) bağımsız bir suç olarak tanımlanmış olsun. Buradaki kast, a) suç teşkil eden fiilin işlenişine, b) bu fiilin işlenişine katkıda bulunmaya yönelik olmalıdır (çifte kast).

Yardım edenin kastının somut bir suça ilişkin olması gerekir. Bu nedenledir ki, suç işlemek için oluşturulmuş örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle ilgili olarak, Kanunda ayrı bir hükme yer verilmiştir (m. 220, f. 7).

İcrasına yardımda bulunulan suçun kasten işlenen bir suç olması gerekir.

Keza, icrasına yardımda bulunulan suçun tamamlanması veya en azından teşebbüs derecesinde kalması gerekir (*kantitatif, niceliksel bağlılık kuralı*).

sorumluluğu cihetine gidilebilmesi için, kişinin suçu önleme yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir. Suçu önleme yükümlülüğünün bulunduğu hallerde, bildirim yükümlülüğünün ihlali dolayısıyla değil, işlenmesi önlenmeyen suça iştirakten ya da suçun ihmali davranışla işlenmiş olmasından dolayı ceza sorumluluğu cihetine gidilmesi gündeme gelebilecektir.” (TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 278, sh. 27 vd.).

Söz konusu dördüncü fıkranın birinci cümlesi Hükümet Tasarısında “*Suçun, üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi hâlinde, cezaya hükmolunmaz.*” iken; bu cümlede Tasarının TBMM Adalet Komisyonunda kanunlaşan şekliyle değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik bağlamında TBMM Adalet Komisyonunun 12.6.2012 tarihli ve Esas: 1/565, 2/90, 2/120, 2/223, 2/257, 2/268, 2/292, 2/322, 2/326, Karar: 12 sayılı Raporunda **gerekçe** olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklıktan çekinmenin düzenlendiği 45’inci maddesi içeriğiyle paralellik kurulmasını sağlamak amacıyla, söz konusu şahsi cezasızlık sebebinden yararlanabilecek olan kişilerin fıkra metninde sayılması yerine, söz konusu 45’inci madde hükmüne içerik olarak yollama yapılması ile yetinilmiştir.

Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki, her ne kadar Türk Ceza Kanununun 279 ve 280 inci maddelerinde benzer içerikte bir hükme yer verilmemiş ise de, Ceza Muhakemesi Kanununun 46’ncı maddesi hükmü karşısında, meslek ve sürekli uğraşları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından da belirli ilişkilerle sınırlı olarak suçu bildirme yükümlülüğü söz konusu değildir ve bildirimde bulunmamak sebebiyle Türk Ceza Kanununun 279 ve 280’inci maddelerinde tanımlanan suçlar oluşmayacaktır. Ceza Muhakemesi Kanununun bu düzenlemesi karşısında, Türk Ceza Kanununun 279 ve 280’inci maddelerinde tanımlanan suçlar bağlamında bu yönde bir hükme yer verilmemiş olması bir eksiklik oluşturmamaktadır.” (TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 278, sh. 128).

¹¹⁸⁸ Konunun suç teorisi bakımından temellendirilmesinde sorunlu açıklamalar için bkz. AKBULUT, Berrin: Genel Hükümler, 5. Bası, sh. 275.

¹¹⁸⁹ Ancak, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bir olayda cinsel saldırı suçunun icrası sırasında hazır ve suçun icrasına katkıda bulunan diğer suç ortağının müşterek fail olarak değil, yardım eden olarak sorumlu tutulması gerektiğine karar vermiştir (CGK, **10.5.2011**, E. 2011/5-83, K. 2011/84). Bu kararın doğru olmadığını belirtmemiz gerekir.

Yardım eden kişiye ceza verirken, işlenen suça ilişkin kanunda öngörülen ceza esas alınmaktadır. Ancak, yardım eden açısından cezada indirim yapılması gerekir. Cezada indirim yapıp yapılmayacağı konusunda hakime takdir yetkisi tanınmamıştır. Çünkü, yardımda bulunmanın ifade ettiği haksızlık, muhteva olarak, icra edilen suça nazaran daha azdır. Yardımda bulunana verilecek ceza, işlenen suçun kanundaki cezasında belli bir oranda indirim yapılması suretiyle tayin edilmektedir. Kanunda öngörülen indirim nisbetleri şöyledir:

Suçun işlenmesine yardımda bulunan kişiye, “*işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.*” (m. 39, f. 1).

765 s. TCK’nın sisteminde, suçun işlenişine bulunulan bir katkı, nitelik itibarıyla yardımda bulunma özelliği arzemesine rağmen, “*yapılmasaydı fiilin işlenişine imkânsız olacaktı*” şeklindeki bir hipotezle “zorunlu fer’î iştirak” olarak tavsif edilmekte ve bu durumda yardımda bulunan suçun tam cezasıyla cezalandırılmaktadır. Buna göre, yardımda bulunanın “*iştiraki inzıam etmeksizin fiilin irtikâbı mümkün olamayacağı sabit olan hallerde o kimse ... tenzilattan istifade edemez.*” (m. 65/son).

Buna paralel olarak doktrinde, yardımda bulunma niteliğindeki bir iştirak katkısının somut olayda arzettiği önem dolayısıyla “*aslî fail*” olarak sorumluluğu gerektirdiği kanaati hâkimdir¹¹⁹⁰.

Aslında mücerret bir yardım etme niteliği arz eden bir iştirak katkısının “aslî fail” olmayı gerektirdiğini ileri süren bu anlayış, suçun işlenişine bulunulan katkılarının neticenin oluşumuna olan *illî etkisini* esas alan yanlış metodolojinin bir kalıntısı mahiyetindedir¹¹⁹¹. Kanımızca, fail – şerik ayırımında suçun işlenişine bulunulan katkının neticenin oluşumu açısından zorunluluk arz edip etmediğinin esas alınması isabetli değildir. Nitekim, bu düşüncelerle, 765 s. TCK’nın etkisiyle Hükümet Tasarısında (m. 42, f. 3) yer alan “zorunlu fer’î iştirak”e ilişkin hükme, yeni TCK’da yer verilmemiştir.

İştirake ilişkin genel hükümler kısmında yer almamakla beraber; 765 s. TCK’nın ve yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısının çeşitli yerlerinde iştirak sistemiyle doğrudan bağlantılı çeşitli hükümlere yer verilmişti.

Bu hükümlerin başında 765 s. TCK’nın “kavga suçu”nu düzenleyen 464. maddesi (Hükümet Tasarısı, m. 233) gelmekteydi.

¹¹⁹⁰ DÖNMEZER/ERMAN II, no.1303; ÖNDER, Genel Hükümler II, 513; TANER, 548/549; GÖZÜBÜYÜK I, 296/297; KUNTER, İHFM XIII(1947), 81/82. Bu düşünce, TCK Öntasarılarına da intikal ettirilmiştir (bkz. ’87 Öntasarısı, m.40, f. 2, gerekçe, sh. 51/52; ’89 Öntasarısı, m. 39, f. 2, gerekçe, sh. 224/225; ’97 Öntasarısı, m. 40, f. 2, gerekçe, sh. 179).

¹¹⁹¹ ROXIN, Täterschaft, 40, 323/324; BLOY, 200/201.

“Kavga suçu” diye bağımsız bir suçun olamayacağı hususundaki görüş¹¹⁹² benimsenerek; Hükümet Tasarısındaki “kavga suçu”na ilişkin hükme yeni TCK’da yer verilmemiştir.

Keza, 765 s. TCK’nın, hukuken savunulabilir hiçbir yönü olmayan 463. maddesi hükmü, Hükümet Tasarısına aynen iktibas edilmişti (m. 232). Söz konusu 463. madde hükmünün adaletsizliğe sebebiyet veren uygulama örnekleri¹¹⁹³ göz önünde bulundurularak, Hükümet Tasarısının 232. maddesine yeni TCK’da yer verilmemiştir.

Birden fazla kişinin iştiraki bir suçun işlenmesini genellikle kolaylaştırmaktadır. Ancak, iştirake ilişkin hükümler, işlenen suça ilişkin kanuni tanımda yer alan fiillerin tamamını gerçekleştirilmeyen, ya da bu tanıma uygun bir davranış gerçekleştirilmeksizin suçun işlenişine iştirak eden suç ortaklarının sorumluluk statülerini belirlemektedir. Bu bakımdan, bir suçun iştirak hâlinde işlenmesi, iştirak statüleri arasında herhangi bir ayırım yapmaksızın, o suçtan dolayı kişilere verilecek cezanın artırılması nedeni olarak mütalâa edilemez. Buna rağmen, yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısında, örneğin hırsızlık (m. 202, 203) ve yağma (m. 207) suçları açısından, bu suçların *iştirak hâlinde* işlenmesinin daha ağır cezayı gerektirdiği yönünde düzenlemelere yer verilmişti.

765 s. TCK ise, hırsızlık suçunun “*ikiden fazla kimseler tarafından birlikte*” işlenmesi halinde faille verilecek cezanın artırılmasını hüküm altına almıştır (m. 491, f. 4; m. 492, f. 3; m. 493, f. 2). Dikkat edilirse, bu hükümlerde “*birlikte*” işlemek ifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle, söz konusu hükümlerin hırsızlık suçunun müşterek faillik şeklinde işlenmesini öngördüğü; buna karşılık, şeriklik hallerini kapsamadığını düşünmekteyiz.

Yeni TCK’da, ancak belirli suçlar bakımından sadece icra hareketlerinin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesinin suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâl olarak kabul edilebileceği düşüncesiyle, hürriyete karşı bazı suçların yanı sıra, cinsel saldırı ve yağma gibi suçlarda, icra hareketlerinin birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi, bu suçların arzettği özellikler göz önünde bulundurularak, ilgili suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir^{1194, 1195}.

¹¹⁹² ÖZGENÇ, “Kavga Suçu” (TCK, m. 464) Üzerine Düşünceler, Yargıtay Dergisi, cilt 19, sayı 4 (Ekim 1993), sh. 477 vd; aynı yazar, Uygulamalı Ceza Hukuku(2), sh. 132 vd.

¹¹⁹³ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 293 vd.

¹¹⁹⁴ Örneğin,

- Cinsel saldırı suçunun (m. 102, f. 3, bent d),
- Tehdit suçunun (m. 106, f. 2, bent c),
- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun (m. 109, f. 3, bent b),
- Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi,

III. Bağlılık Kuralı

Suçun icrasına iştirak etmekle beraber, suçun işlenişine bulunduğu katkı suçun kanundaki tarifine uygun olmayan diğer suç ortaklarının da gerçekleşen haksızlıktan sorumlu tutulabilmeleri gerekir. Suçun işlenişine bulunduğu katkı kanunî tarifteki haksızlığı gerçekleştirmeyen diğer suç ortakları, **şerik** olarak nitelendirilmekte ve kanunun şerikliğe ilişkin genel hükümleri, **sorumluluk alanını genişleten hükümler** olarak mütalaa edilmektedir¹¹⁹⁶. **Azmettirme ve yardım etme** olarak iki farklı görünüş şeklinin söz konusu olduğu şeriklikte, suç ortaklarının gerçekleşen kanunî tarife uygun haksızlıktan sorumlu tutulabilmeleri ancak **bağlılık kuralı**¹¹⁹⁷ vasıtasıyla mümkün olabilecektir. Fail, gerçekleşen kanunî tarife uygun haksızlıkla, suçun objesiyle doğrudan temas halinde iken; şerik için böyle bir doğrudan temas söz konusu değildir. Şerik, faille olan şahsi bağlantısı nedeniyle ve ancak *bağlılık kuralı* vasıtasıyla söz konusu haksızlıktan sorumlu tutulacaktır¹¹⁹⁸.

inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının (m. 119, f. 1, bent c),

- Yağma suçunun (m. 149, f. 1, bent c),

- Görevi yaptırmamak için direnme suçunun (m. 265, f. 3),

birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.

¹¹⁹⁵ Keza, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrasında “*Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.*” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükmün gerekçesinde şu açıklamalar yer almaktadır: Söz konusu “... *ikinci fıkra hükmüyle*, (Kanunda) **tanımlanan suçların ve kabahatlerin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacağı kabul edilmiştir. Buna göre, cezada artırım yapılabilmesi için, (Kanunda) tanımlanan suçlardan veya kabahatlerden birinin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi gerekir. Eklenen fıkra da yer alan “birlikte” ibaresi, müşterek failliği ifade etmektedir. Türk Ceza Kanununa göre, suçun icra hareketlerinin birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmiş olması halinde, müşterek faillik söz konusudur. Ancak, (söz konusu) fıkraya göre suçun cezasının artırılabilmesi için, müşterek fail sayısının en az üç kişi olması gerekir. Kabahatler Kanununda, kabahatlere iştirakle ilgili olarak “tek tip fail sistemi” kabul edilmiş olmakla birlikte, kabahatin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde de idarî para cezası artırılacaktır. Bu bakımdan kabahatin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 37’nci maddesinin müşterek failliğe ilişkin birinci fıkrası hükmünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1275, sh. 12 vd. Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sh. 36 vd.).**

¹¹⁹⁶ MAURACH, Lb., 618; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 229/230; CRAMER, Schönte/Schröder, Vorbem. vor §§ 25 ff. kn. 7; BLEI, Allgemeiner Teil, 253 vd.; ROXIN, Täterschaft, 327, 328, 595; aynı yazar, Kriminalpolitik, 20; JESCHECK, Lb., 620; SAMSON, SK, § 25 kn. 3; SCHMIDHAEUSER, Lb., 14/3 vd. Türk hukukunda teşebbüse ilişkin hükümler açısından aynı doğrultuda görüş için bkz. SÖZÜER, 147/148.

¹¹⁹⁷ “*Akzessorietätsprinzip*”. Kural hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. DEMİREL, Muhammed: *Suçta İştirakte Bağlılık Kuralı*, İstanbul, Aralık 2017; ÖNOK, Müşterek Suç Girişimi, sh. 76 vd.

¹¹⁹⁸ Kavram hakkında bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 141 vd., 316.

Şeriklik hallerinde her ne kadar şerikin bir fiil icra etmesi gerekli ise de; bu fiil, kanunî tariftteki haksızlığı gerçekleştirecek nitelikte değildir. Failin sorumluluk sebebi olan kanunî tarife uygun haksızlıkla doğrudan temas halinde olmasına karşılık; şerikin bu ilişkisi *ancak fail aracılığıyla* gerçekleşmektedir. İcra ettiği fiil, ilgili suç tanımıyla korunan *hukuki değeri* ihlal mahiyetinde olan¹¹⁹⁹ ve ancak suçun kanunî tarifine uygun haksızlık niteliğine varmayan şerik, *fail ile doğrudan ilişki halindedir*.¹²⁰⁰ **Bağlılık kuralı** şerikin söz konusu haksızlıktan sorumluluğunu sağlamaktadır. Failin gerçekleştirdiği kanunî tarife uygun haksızlıktan şerikin sorumluluğu, kendisinin bu sorumluluk objesiyle (haksızlıkla) doğrudan bağlantısı olmadan, sadece faille şahsi bir irtibatın bulunması sebebiyle ancak bağlılık kuralı vasıtasıyla mümkün olmaktadır¹²⁰¹.

Bağlılık kuralı, fail olarak sorumluluk için ilgili suç tanımına göre gerekli şartların bulunmaması halinde bunların yerine ikame edilmekte ve bu suretle, şerikin kanunî tarife uygun haksızlıktan sorumluluğu sağlanmaktadır. Böylece; fiil üzerinde hakimiyet kuramadığı veya özel faillik vasfını bünyesinde taşımadığı için fail olamayan bir suç ortağı, *bağlılık kuralı* vasıtasıyla gerçekleşen haksızlıktan sorumlu tutulabilmektedir. Bu yönü itibarıyla, **bağlılık kuralının çifte fonksiyonundan**¹²⁰² bahsetmekteyiz. Şeriklik halinde cezalandırılabilirliğin dayanağını teşkil eden *bağlılık kuralının* söz konusu fonksiyonu ifa edebilmesi için; esas fiilin bir *haksızlık* ifade etmesi, başka bir deyişle, mutlaka **kasten** işlenmesi ve **hukuka aykırı** olması gerekir ve yeterlidir¹²⁰³; kanunî tarife uygun

¹¹⁹⁹ STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 859; ROXIN, LK(10), Vorbem. vor § 26 kn. 2 vd.; CRAMER, Schönke/Schröder, Vorbem. vor §§ 25 ff. kn. 22; OTTO, Strafbare Teilnahme?, Festschrift für Richard Lange, 1976, sh. 210; VOGLER, Zur Frage der Ursächlichkeit der Beihilfe für die Haupttat, Festschrift für Ernst Heintz, 1972, sh. 299, 301.

¹²⁰⁰ BLOY, 191, 250 vd., 316 vd.

¹²⁰¹ BLOY, 251; VOGLER, Heintz-F., 299/300. LÜDERSEN ise, bağlılık prensibinin rolünü tamamen inkâr etmekte ve şerikin sadece kendi gerçekleştirdiği haksızlıktan sorumlu olacağı fikrine varmaktadır (LÜDERSEN, Zum Strafgrund der Teilnahme, 1967, sh. 25, 28, 119.). Aynı şekilde, bağlılık prensibini Türk hukukunda reddeden yazarlar: KUNTER, İHFM XIII(1947), 76, 92; TOROSLU, 186. Buna karşılık ROXIN, şerikliğin cezalandırılmasının hukuki esası bakımından sentez bir çözüm şekli önermektedir: Şerik bir taraftan failin gerçekleştirdiği haksızlıktan, diğer taraftan ise bizzat kendi gerçekleştirdiği haksızlıktan sorumlu olmaktadır (ROXIN, LK[10], Vorbem. vor § 26 kn.3, 7, 17).

¹²⁰² “Doppelfunktion der Akzessorietät”: BLOY, sh. 212/213, 316/317.

¹²⁰³ Esas fiilin kasten işlenmesi zorunluluğunu arayan yazarlar: BAUMANN, Beiträge, 219, 221; BAUMANN/WEBER, 535 vd.; BOCKELMANN, Täterschaft und Teilnahme, 5; aynı yazar, Str. Untersuchungen, 90/91; aynı yazar, Zur Problematik der Beteiligung an vermeintlich vorsätzlich rechtswidrigen Taten, Festschrift für Wilhelm Gallas, 1973, sh. 261 vd.; WELZEL, Lb. 113; aynı yazar, JZ 1953, 763 vd.; aynı yazar, JZ 1954, 128 vd.; GALLAS, Beiträge, 105, 117/ 118, 145/146; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, 379, 380; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil, kn. 880; JESCHECK, Lb., 594; aynı yazar, SchZStr. 71(1956), 238; JAKOBS, Lb., 22/12; BLOY, 234, 313.

(esas) fiili gerçekleştiren suç ortağının, yani failin ayrıca kusurlu olmasına gerek yoktur. Keza, cezayı hafifleten veya ortadan kaldıran şahsi sebepler, ancak ilgili suç ortağı açısından hukuki sonuç doğururlar¹²⁰⁴.

Keza, bağluluk kuralı, özgü suçun özel faillik vasfını taşıyan kişi ile bu vasfı taşımayan kişinin iştirakiyle işlenmesi halinde, özel faillik vasfını taşımayan kişinin bu suçtan dolayı şerik olarak sorumluluğunu sağlama yönünde bir fonksiyon icra etmektedir. *Bağluluk kuralının çifte fonksiyonu* gereğince; özel yükümlülük altında bulunmayan kişi, özel yükümlülük altında bulunan bir diğer kişinin işlediği özgü (mahsus) suça iştirak etmesi halinde, bu suçtan ancak şerik (azmettiren veya yardım eden) olarak sorumlu tutulacaktır. Bu itibarla; özel yükümlülük altında bulunmayan kişinin, özgü suçun işlenişine bulunduğu katkının mahiyeti ne olursa olsun, bu suçtan ancak şerik olarak sorumluluğu cihetine gidilecektir^{1205,1206}.

Buna karşılık esas fiil için kastın mevcudiyetine lüzum görmeyen yazarlar: MEZGER, LK(8), § 50, kn. 5d; aynı yazar, Stub., 136, 227, 228; SCHÖNKE/SCHRÖDER(17), Vorbem. vor § 47 kn. 87, § 48 kn. 16, 17, § 49 kn. 12; SCHMIDHAEUSER, Lb., 14/87 vd.; aynı yazar, Stub., 10/22; LANGE, Zur Teilnahme an unvorsätzlicher Haupttat, JZ 1959, 560 vd.

Ayrıca, kural olarak esas fiil için kastı aramamakla beraber bazı istisnâ durumlarda (meselâ, mahsus suçlarda özel faillik vasfını haiz olan ve fakat kastı olmayan kişinin bu özel faillik vasfını haiz olmayan kişi (=extraneus) tarafından suç işlemeye sevk edilmesi durumunda) ortaya çıkan cezalandırılabilme boşluğunun doldurulabilmesi amacıyla, kasten işlenmeyen esas fiile de iştirakin kabil olduğu görüşünü ileri süren yazarlar: ENGİSCH, ZStW 66(1954), 387/388; aynı yazar, E. Schmidt-F., 116 vd.; ROXIN, Täterschaft, 367 vd., 552 vd.; Cramer, Schönke/Schröder, Vorbem. vor §§ 25 ff. kn. 32/33.

¹²⁰⁴ Bu konuda bilgi için ayrıca bkz. ÖZGENÇ, *Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi*, in: *Yargıtay Dergisi*, Ocak-Nisan 1999, sayı 1-2, sh. 70 vd.; ayrıca, Kamu Hukuku Arşivi, yıl 2, sayı 1, Şubat 1999, sh. 5 vd.

¹²⁰⁵ TCK'nın 40. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemenin dayanağını oluşturan bu teorik açıklamalara eleştiri için bkz. TOROSLU, Genel Kısım, 8. bası, sh. 301.

¹²⁰⁶ Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 13.2.2014 tarihli ve E. 2012/12632, K. 2014/1375 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; kamu görevlisi olmayan A, kamu görevlisi B'nin rüşvet teklifini C'ye iletir ve bu teklifi kabul eden C'den aldığı parayı getirerek B'ye verir.

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin kabulüne göre, rüşvete aracılık eden kişi olarak A, ancak rüşvet suçuna yardım eden sıfatıyla cezalandırılabilir ve bu nedenle cezasında TCK, m. 39 hükümlerine istinaden indirim yapılması gerekir. Daire bu kararını TCK, m. 40, f. 2'ye dayandırmıştır.

Daire, bu kararında, TCK, m. 252, f. 5 hükmünü görmezlikten gelmiştir:

“Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının sağlanması veya rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.”

Bu itibarla, söz konusu karar doğru değildir.

Rüşvet suçu, bir **karşılaşma suçu** olarak, **çok faili suç**dur. Rüşvet suçunun bir alanı bir de vereni mevcuttur. Bu suçun faillerinden sadece rüşveti alan, kamu görevlisidir; rüşveti veren kamu görevlisi değildir. Rüşvete aracılık edenin de kamu görevlisi olması gerekmektedir. Esasında rüşvete aracılık eden kişi, rüşvet veren ve alan ile birlikte rüşvet fiilinin işlenişinde müşterek hakimiyet tesis etmektedir. Bu nedenle, rüşvete aracılık eden kişinin, işlenen rüşvet suçunun **müşterek faili** sıfatıyla sorumlu tutulması gerekmektedir.

Bu itibarla, bağlılık kuralı şeriklik halinde cezalandırılabilmenin dayanağını oluşturmaktadır¹²⁰⁷.

Ancak, şeriklik, failliğin yumuşatılmış bir şekli olarak da anlaşılmamalıdır. Buradaki fark, suç teşkil eden vakıa ile olan temasın doğrudan veya dolaylı oluştundan kaynaklanmaktadır. Faillik ve şerikliğin ayırımında ön plâna çıkan, her bir sorumluluk şeklindeki haksızlık muhtevasının *gereçeklendirilmesi* olmaktadır. Bu itibarla, söz konusu ayırımı haksızlık muhtevasının bir **derecelendirilmesi** mevcut **değildir**¹²⁰⁸. İştirak şekilleri arasında haksızlık muhtevası yönünden oluşturulan fark bir **nicelik farkı değil**, bir **nitelik farkıdır**¹²⁰⁹.

Bağlılık kuralının gereği olarak şeriklik halleri haksızlık içeriklerini failin işlediği fiilden aldığına göre, bu fiilin en azından icrasına başlanmalıdır ki, iştirak hükümlerine göre cezalandırma yoluna gidilebilsin¹²¹⁰. Bu nedenle, maddenin üçüncü fıkrasında **niceliksel bağlılık kuralına** yer verilmiştir. Buna göre; “*Suçta iştiraktan dolayı sorumlu tutulabilmek için, ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir.*” Ancak, belirtmek gerekir ki, azmettirme halinde, azmettirme fiili de başlı başına bir haksızlık ifade etmektedir. Azmettirmede, serbest iradesiyle hareket eden bir şahsın korrupte edilmesi, tefessüh ettirilmesi söz konusudur; yani suç işlemeyi aklının köşesinden dahi geçirmeyen bir kişide suç işleme yönünde bir karar oluşturulması sağlanmaktadır. Bu nedenle, esas fiilin icrasına henüz başlanmamış olsa da, azmettirme olgusu başlı başına bir haksızlık ifade etmektedir. Nitekim, bu husus, 38. madde gerekçesinin ikinci paragrafında açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Yeni TCK’da, 765 s. Kanunun ve Hükümet Tasarısının aksine, “*kışisel ağırlatıcı nedenlerin*” ve “*fiili ağırlatıcı nedenlerin şeriklere uygulanması*” hükümlerine yer verilmemiştir. 765 s. TCK’da yer verilen bu hükümler, bağlılık kuralının henüz bilinmediği 19. yüzyıl ceza hukuku düşüncesinin ürünü olarak kabul edilmişlerdi. Kanunda bağlılık kuralına ilişkin hükme yer verdikten, bu hükümlerin korunmasına gerek kalmamıştır.

765 s. TCK’nın 66. maddesinde, “*şahsi ağırlatıcı sebeplerin sirayeti*”ne; 67. maddesinde ise, ikincisi ise, “*fiili ağırlatıcı sebeplerin sirayeti*”ne ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Yargıtay’ın söz konusu kararı, mülga 765 sayılı TCK’da yer alan “rüşvet alma suçu” ve “rüşvet verme suçu” şeklindeki iki ayrı suç tanımına dayanmaktadır. Oysa yeni TCK’nın sisteminde “rüşvet verme suçu” ve “rüşvet alma suçu” şeklinde bir ayırım yer almamaktadır. TCK, m. 252’de **rüşvet suçu** tanımlanmıştır. Bu maddede rüşvet verenin ve rüşvet alanın ne suretle cezalandırılacağına ilişkin iki ayrı fıkrada hüküm altına alınması, bu ayırımın hukuki dayanağını oluşturmaz.

¹²⁰⁷ VOGLER, Heinitz-F., 300; BOCKELMANN, Str. Untersuchungen, 122.

¹²⁰⁸ BLOY, 111-112, 317.

¹²⁰⁹ SAX, JZ 1963, 335; BLOY, 112/113.

¹²¹⁰ TOROSLU, 190/191; aynı yazar, TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, 91; ayrıca ÖNCÜL, TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, 108.

Bu sistemde, klasik ceza hukuku anlayışının bir sonucu olarak, suçun unsurlarının yanı sıra, “ağırlatıcı sebepler” ve “hafifletici sebepler”e yer verilmiştir. Doktrinde, faile verilecek cezanın artırılmasını veya eksiltilmesini sağlamanın dışında bu sebeplerin hukuki niteliği üzerinde durulmamıştır. Bu nedenledir ki; meselâ haksız tahrik hali¹²¹¹ ve faal nedamet¹²¹², birer “hafifletici sebep” olarak kabul edilmiştir.

Bu “ağırlatıcı veya hafifletici sebepler”, “fiile bağlı veya şahsa bağlı sebepler” olarak ayırımı tabi tutulmuştur. Meselâ, bir insanın zehirlemek suretiyle öldürülmesi (765 s. TCK, m. 449, f. 2), kasten adam öldürme suçu açısından “fiile bağlı bir ağırlatıcı sebep”tir. Keza, bir insanın silahla yaralanması (765 s. TCK, m. 457, f. 1), kasten müessir fiil suçu açısından “fiile bağlı bir ağırlatıcı sebep” olarak telâkki edilmektedir. Hırsızlık suçunda çalınan şeyin değerinin “pek fa-hiş” veya “pek hafif” olması, bu suç açısından “fiile bağlı ağırlatıcı veya hafifletici sebep”tir (765 s. TCK, m. 522).

Buna karşılık, meselâ bir insanın babasını öldürmesi halinde, bu üstsoy-altsoy (usul-füru) ilişkisi¹²¹³, adam öldürme suçu açısından “şahsa bağlı bir ağırlatıcı sebep”tir. Keza, ırza tecavüz suçunun “fuhşu kendine meslek edinen bir kadın hakkında irtikâp” olunması, bu suç açısından “şahsa bağlı bir hafifletici sebep” idi¹²¹⁴.

Fakat, bazı hallerde cezayı artıran veya hafifleten sebebin fiile mi yoksa şahsa mı bağlı olduğunu tayin etmek kolay değildir. Meselâ, adam öldürmek suçunun taammüden işlenmesi, “canavarca bir his sevki ile” işlenmesi, bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak, işlenmiş bir suç gizlemek gibi bir maksatla işlenmesi halinde, bu sübjektif hallerin münhasıran şahsa bağlı ağırlatıcı sebep mi yoksa fiile bağlı ağırlatıcı sebep mi olduğunu söylemek, mümkün değildir¹²¹⁵.

765 s. TCK sistemi, suç ortaklarından birisiyle ilgili olarak “cezayı artıran şahsi sebep”in varlığı halinde, bu sebebe istinaden diğer suç ortaklarının cezasında artırım yapabilmek için “vukuf şartı”nı aramıştır (m. 66)¹²¹⁶. Yani, suç ortaklarından birisiyle

¹²¹¹ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1087.

¹²¹² DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1277.

¹²¹³ *Dönmezer/Erman* ırza tecavüz suçu açısından fail ile mağdur arasındaki usul-füru ilişkisinin fiile bağlı bir ağırlatıcı sebep olduğu düşüncesindedirler (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1284). *Erem* ise, usul-füru ilişkisinin hem kişisel hem de fiili bir nitelik taşıdığını, bu gibi hallerde fiili unsurun daha hakim görüldüğünü belirtmektedir (EREM/DANIŞMAN/ARTUK, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. bası, Ankara 1997, sh. 414).

¹²¹⁴ 765 s. TCK, m. 438. Ancak, bu madde hükmü, 21.11.1990 tarih ve 3679 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır (m. 28).

¹²¹⁵ *Dönmezer/Erman*’a göre, “tasarlama ve canavarca hissin kişisel birer ağırlatıcı sebep olduğundan şüphe edilemez” (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1280).

¹²¹⁶ Bu “vukuf”, Kanunun ifadesiyle, suça iştirak anında aranmalıdır. Bu ifadeden hareket eden *Dönmezer/Erman*, vukufun “suçun işlendiği zamanda değil, iştirakin gerçekleştiği, yani iştirak iradelerinin meydana geldiği anda” aranması gerektiği fikrindedirler (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1304). Kanaatimizce bu yorum, kanunun lafzına bağlı daraltıcı bir yorumdur.

le ilgili olarak mevcut olan “cezaıı ağırlaştırıran şahsi bir sebep”in varlığını diğır suç ortaklarının bilmesi halinde, bu sebep dolayısıyla bunların cezasını artırmak mümkün olacaktır¹²¹⁷. Kendileri açısından “cezaıı ağırlaştırıran şahsi sebep”in varlığı söz konusu olmamasına rağmen bu suç ortaklarının cezasında artırım yapılacaktır. Bu konuda izlenecek yol řu řekilde izah edilmiştir: “Kişisel ağırlatıcı sebebin sirayeti sonucunda kendisine bu sebep sirayet ettirilen řerik, sözü geen ağırlatıcı sebep hesabına katılmak suretiyle cezalandırılacak, fakat, bundan sonra, 66. maddenin ikinci cümlesinde kabul edildiğı üzere bu cezada indirim yapılabilir”^{1218, 1219}.

Dikkat edilmelidir ki, bu sistemde “cezaıı artıran şahsi sebep”in sirayeti için bunun hangi suç ortağıyla ilgili olarak gerekleşmiş olduğunun bir önemi yoktur¹²²⁰.

Söz konusu Kanunun 67. maddesinde ise, “cezaıı artıran fiilî sebepler”in sirayeti düzenlenmiştir. Bu sirayet için de “vukuf şartı” aranmaktadır. Bu vukuf, Kanunun ifadesiyle, fiilin işlendiğı zamanda gerekleşmelidir^{1221,1222}.

¹²¹⁷ Dönmezer/Erman, sadece vukufun yeterli olmadığı; bunun yanı sıra, “cezaıı artıran şahsi sebep”in “suun icrasını kolaylaştıran” bir etki icra etmesi gerektiğı düşüncesindedirler (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1279).

¹²¹⁸ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1305. Kanunun ifade tarzından hareketle hakime indirim konusunda bir takdir yetkisinin tanınmadığı, zorunlu indirim sisteminin kabul edildiğı savunulabilir ise de; 66. madde hükmünün kaynak kanun metni esas alınmak suretiyle yorumlanması halinde, aksi sonuca ulaşılmaktadır (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1305; EREM/DANIŞMAN/ AR-TUK, sh. 413; KUNTER, Su Ortaklığında Sorum ve Ceza, İHFM XIII[1947], sh. 84, dn. 37).

¹²¹⁹ Yargıtay, Kanunun lafzına bağılı kalarak 66. maddenin ikinci cümlesi açısından şöyle bir ayırım yapılmasını uygun görmüştür:

«TCK'nın 66. maddesinin “ancak” sözcüğü ile başlayan (cümlesi) iki tür ceza indirimine yer vermiştir. Birinci bölümde idam ve müebbet ağır hapis cezaları dışında kalan cezalardaki indirimde mahkemeye değıerlendirme yetkisi tanınmışken, ikinci bölümde idam ve müebbet ağır hapis cezasında yapılacak indirimi yasa belirlemiş ve mahkemeye değıerlendirme yetkisi vermemiştir.»: CGK., 23.2.1987, 1-486/69 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1015 vd. Aynı mealde karar için ayrıca bkz. 1. CD, 22.3.1983, 485/947).

¹²²⁰ Önder, “fer’î faildeki şahsi ağırlatıcı sebebin diğır suç ortaklarına sirayeti(ni) düşündürücü” bulunmaktadır (ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 514).

¹²²¹ Kanun, “cezaıı artıran şahsi sebepler” bakımından kabul ettiğı cezada önce artırım, bilahare belli oranda indirim sistemini burada kabul etmemiştir. Bu nedenle, “cezaıı artıran fiilî sebep”e vakıf olan bütün suç ortaklarının cezası, bu sebep esas alınarak tayin edilecektir (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1306).

¹²²² İlginçtir ki, Yargıtay, müsterek faillikte sınırın aşılması halinde dahi 67. madde hükmünün uygulanabilip uygulanamayacağı meselesini tartışma konusu yapmıştır:

Soygun yapmak üzere anlaşılan TC, TU ve KA bir gıda pazarına girerek soygun yapmak isterler. KA silahını çıkararak “bu bir soygundur, kimse kıpırdamasın” ihtarında bulunur. Dükkan sahibi AD, KA'nın üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirmek ister. Ancak, diğır suç ortaklarından TU, ani bir hareketle tabancasını çekip iki el ateş ederek AD'yi öldürür. Bu olayda TC'nin öldürme fiiline hiçbir dahli olmamıştır. Bu durumda “özömlenecek sorun; TC hakkında TCK'nın 67. maddesinin uygulanması suretiyle öldürme fiilinden sorumlu tutulup tutulamayacağıdır. (67.) maddede sadece vukuf şartı aranmıştır. (Bu da, bir sebebin) gerekleşceğini kesin olarak bilme(yi ifade eder. Bir sebebin) meydana gelebilirliğini veya gelebileceğini öngörmek vukuf sayılmaz.

Söz konusu hükümler, günümüz suç genel teorisinin iştirake ilişkin prensipleriyle uyuşmamaktadır ve bu nedenle, TBMM Adalet Komisyonunda yapılan çalışmalar sırasında yeni TCK'ya ilişkin Hükümet Tasarısının aynı içerikteki 43 ve 44. maddeleri hükümleri metinden çıkarılmıştır.

Şu örneklerin, konunun açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz:

A'nın, bir suçun delillerini gizlemek amacıyla işlediği kasten öldürme suçuna B, silah tedarik etmek suretiyle iştirak etmiş (yardımda bulunmuş) olabilir. Bu durumda B'yi A'nın işlediği kasten öldürme suçunun nitelikli halinden (m. 82, f. 1, bent h) şerik olarak sorumlu tutmak gerekir. B, A'nın güttüğü bu amacı bilmeyebilir; yani B'nin kasten öldürme suçunun bu nitelikli unsuru açısından kastı mevcut olmayabilir. Bu durumda; her ne kadar A, güttüğü amaç itibarıyla suçun nitelikli şekline nazaran cezalandırılacak ise de; B'yi kasten öldürme suçunun temel şekline (m. 81) istinaden şerik (yardım eden) olarak sorumlu tutmak gerekecektir.

Babasını öldürmeye karar vermiş olan bir kişiye zehir tedarik etmiş olan şahıs, kasten öldürme suçunun nitelikli şeklinin işlenişine yardım eden olarak sorumlu tutulacaktır. Her ne kadar yardım eden ile mağdur arasında üstsoy-altsoy ilişkisi mevcut değilse de, bu ilişki sadece fail ile mağdur arasında mevcut ise de; yardım eden, işlenen kasten öldürme suçunun bu nitelikli şekline iştirak etmiş olması dolayısıyla yardım eden (şerik) sıfatıyla sorumlu tutulacaktır.

Bu kişi, kasten öldürme suçunun icra hareketlerini mağdurun oğlu ile birlikte gerçekleştirmiş olabilir. Bu durumda, mağdurun oğlunu, mağdurla aralarındaki üstsoy-altsoy ilişkisi nedeniyle, kasten öldürme suçunun nitelikli şeklinden (m. 82, f. 1, bent d) dolayı fail olarak cezalandırılması gerekmektedir. Buna karşılık, mağdurun oğlu olmayan diğer suç ortağını ise, kasten öldürme suçunun temel şeklinden (m. 81) dolayı fail olarak cezalandırmak gerekecektir. Mağdurla aralarında üstsoy-altsoy ilişkisinin bulunmaması nedeniyle, bu kişinin fiili aynı zamanda kasten öldürme suçunun nitelikli şekline (m. 82, f. 1, bent d) yardım eden olarak sorumluluğu gerektirse de, failliğin şerikliğe göre asliliği kuralı gereğince, sadece kasten öldürme suçunun temel şeklinden (m. 81) dolayı fail olarak cezalandırılması mümkündür.

Failin sıfatının suçun nitelikli unsurunu oluşturması halinde dahi aynı şekilde düşünmek gerekir. Meselâ failin kamu görevlisi olması resmî belgede sahtecilik suçunun nitelikli unsurunu oluşturmaktadır (m. 204, f. 2). Bir kamu görevlisinin

TC'nin iradesi ve ittifakı gasp içindir. Bir anlık gelişme ve değişme sonucu ortaya çıkan öldürmede dahli yoktur ve vukufundan bahsedilemez. Diğer (suç ortaklarının) anlaşma hududunu tecavüz ederek meydana getirdikleri aşkın ve taşkın sonuç; birleşmiş iradelerinin hilafına ve rağmen bir mahiyet gösterdiğinden; fiili ilk suç için orada bulunmaktan ibaret olan TC'nin yeni ve değişik suçtan sorumluluğu mümkün değildir. Bu ahvalde TCK'nın 67. maddesindeki sirayet hükmü uygulanamaz.”: CGK., 27.10.1986, 1-293/466 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1019 vd.).

işlediği resmî belgede sahtecilik suçuna, bu sıfatı taşımayan bir şahıs (extra-neus) meselâ yol göstermek, ihtiyaç duyulan malzemeyi tedarik etmek veya azmettirmek suretiyle iştirak etmiş olabilir. Bu gibi durumlarda özel faillik vasfını taşımayan şahsı kamu görevlisinin işlediği resmî belgede sahtecilik suçuna şerik (azmettiren veya yardım eden) olarak sorumlu tutmak gerekecektir¹²²³.

Bunun tersi de düşünülebilir: Herhangi bir şahsın işlediği resmî belgede sahtecilik suçuna (m. 204, f. 1) bir kamu görevlisi meselâ azmettirmek, teşvik etmek, yol göstermek suretiyle iştirak etmiş olabilir. Burada iştirak edilen suç, herhangi bir şahsın işlediği resmî belgede sahtecilik suçudur. Şerik (azmettiren veya yardım eden) sıfatıyla suça iştirak eden şahıs her ne kadar kamu görevlisi ise de, 204. maddenin birinci fıkrasında tanımlanan resmî belgede sahtecilik suçuna iştiraktan dolayı cezalandırılacaktır. Çünkü, bağlılık prensibi gereğince, şerik olarak sorumluluğu gerektiren iştirak katkısı haksızlık muhtevasını failin fiilinden almaktadır.

Müşterek faillikte farklı düşünmek gerekir. Şöyle ki, meselâ resmî belgede sahtecilik suçunu özel faillik vasfını (kamu görevlisi sıfatını) taşıyan A ile herhangi bir şahıs olan B birlikte de işlerler. Bu durumda her iki suç ortağı sahte resmî evrak düzenleme vakıası üzerinde müşterek hakimiyet kurarlar. Ancak, özel faillik vasfını taşımayan B, resmî belgede sahtecilik suçunun temel şekli (m. 204, f. 1) açısından A ile birlikte müşterek fail olarak sorumlu tutulacaktır. Fakat, özel faillik vasfını taşıyan A'yı ayrıca resmî belgede sahtecilik suçunun nitelikli şekli açısından müstakil fail olarak sorumlu tutmak gerekecektir. B ise, bu suçun nitelikli şekline ancak yardım eden, yani şerik olarak sorumlu tutulmak gerekir¹²²⁴. Ancak, aslî norm-talî norm ilişkisinin söz konusu olduğu hallerde kişiyi sadece aslî normun ihlâli dolayısıyla cezalandırmak gerekir. Aynı fiille ayrıca tali normun ihlâl edilmiş olması dolayısıyla faile ayrıca ceza verilmeyecektir. Faillğe nazaran şeriklik hali talî norm karakteri arzettiği için; bu olayda B'yi sadece resmî belgede sahtecilik suçunun temel şeklinden (m. 204, f. 1) dolayı (müşterek) fail olarak cezalandırmak gerekecektir¹²²⁵.

¹²²³ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 170 vd.

¹²²⁴ ÖZGENÇ, Suça İştirak, sh. 291.

¹²²⁵ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 15.11.2016 tarihli E. 2014/11-402, K. 2016/431 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, Belediye Evlenme Memuru olan TE, bayan TC ile bay AÖ arasında TC'nin bilgisi olmadan evlenme akdi düzenler.

Evlenme akdi bir resmi belgedir. Bu belge, evlendirme memuru tarafından düzenlenir. Karara konu teşkil eden olayda evlendirme memuru göreviyle bağlantılı olarak bir sahte resmi belge düzenlemiştir. Bu belgenin düzenlenmesi bağlamında TE hakkında TCK, m. 204, f. 2 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekir.

TE, bu sahte belgeyi AÖ ile anlaşılarak düzenlemiştir. Bu itibarla AÖ de bu resmi belgede sahtecilik suçunun müşterek failidir. Ancak AÖ hakkında TCK, m. 204, f. 2 hükmüne istinaden değil, f. 1 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekir.

Dikkat edilmelidir ki; müşterek faillik açısından bağıllık prensibinin herhangi bir etkisi yoktur. Bu itibarla, yukarıdaki örnekte B, A'nın kamu görevlisi sıfatını bilmiş olsa bile, ancak 204. maddenin birinci fıkrasına istinaden müşterek fail olarak cezalandırılacaktır. Diğer müşterek failin kamu görevlisi olması dolayısıyla B'nin cezasında herhangi bir artırım cihetine gidilmemesi gerekir^{1226,1227}.

Ekskurs 8. Bağıllık Kuralına İlişkin Uygulama Sorunu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 25.06.2014 tarihli ve E. 1428, K. 2014/3654 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, miras paylaşımından kaynaklanan uyuşmazlık sebebiyle, Güler, elindeki av tüfeğini kızı Cemile'ye vererek, kardeşi Ali Kemal'i kast ederek “vur” talimatı verir. Bunun üzerine Cemile dayısı Ali Kemal'i hedef alarak tüfikle ateş eder. İsabet alan Ali Kemal ölür. Bunun üzerine Güler ile annesi Halime arasında itiş kalkış meydana gelir. Halime yere düşer. Güler, Cemile'nin elinden av tüfeğini alarak yere düşen Halime'nin kafasına dipçiğiyle müteaddit defa vurur. Halime aldığı darbeler sonucu ölür.

Bu olayda iki ayrı kişiye karşı kasten öldürme suçu işlenmiştir.

Ali Kemal'e karşı işlenen kasten öldürme suçunda Güler azmettirenidir. Fail ise Cemile'dir. Her ne kadar Ali Kemal, Cemile'nin dayısı ise de, dayı yeğen ilişkisi TCK'nın 82. maddesinin birinci fıkrasının d bendinde bu suçun nitelikli hali olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle Esas Mahkemesi Cemile hakkında TCK'nın 81. maddesi hükmüne istinaden, yani **kasten öldürme suçunun temel şekli**nden dolayı cezaya hükmetmiştir. 1. Ceza Dairesi de, Esas Mahkemesinin hükmünü bu yönü itibarıyla doğru bulmuş ve onamıştır.

¹²²⁶ TULAY, Muhammet Emre: *Suç Ortaklarının Cezai Sorumluluğu Üzerinde Kamu Görevlisi Sıfatının Hukuki Etkisi*, in: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 70, sayı 4, yıl 2021, sh. 1223 vd.

¹²²⁷ Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 16.04.2014 tarihli ve E. 2014/1118, K. 2014/4281 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda Osmaneli Tapu Sicil Müdürü olarak görev yapan EE ile, bu kurumdan emekli olmasına rağmen, EE'nin talebi üzerine, iş ve işlemlere yardımcı olmak üzere tapu sicil müdürlüğünde gayri resmi olarak çalışmaya devam eden İA, “irade ve eylem birliği içerisinde hareket ederek farklı tarihlerde tapuda işlem yaptıran kişilerden, gerçekte tahsilat yetkileri olmadığı halde, bu konuda yetkili oldukları izlenimi uyandırarak tapu işlemlerinde yükümlüsü tarafından Mal Müdürlüğüne veya ilgili bankaya yatırılması gereken tapu harç ve döner sermaye ücretlerini esasen olması gereken miktarlardan daha fazla olacak şekilde ilgililerden tahsil” ederler; “harç ve döner sermaye ücretlerini hiç yatırmamak veya eksik yatırmak suretiyle kalan paraları mal” edinirler.

Bu olayla ilgili olarak Daire şu kararı vermiştir: “EE'nin görevinin sağladığı güveni kötüye kullanarak gerçekleştirdiği hileli davranışlarla tapuda işlem yapan mağdurları kendisi ve İA'ya yarar sağlanmasına ikna ettiği; eylemlerin farklı tarih ve ortamlarda gerçekleştirilmesine bağlı olarak **mağdur adedince ikna suretiyle irtikap suçunu** oluşturduğu; İA'nın TCK'nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde bulunan bu eylemlere aynı Kanunun 39. maddesi kapsamında **yardım eden** olarak iştirak ettiği; gözetilmeden, dosya kapsamı, oluşturma düşmeyen gerekçeler ve yanlışlıklar değerlendirilerek sonucu bazı eylemlerden beraet kararları verilmesi, bazı eylemlerin ise EE yönünden görevi kötüye kullanma, İA yönünden nitelikli dolandırıcılık olarak kabulüyle mahkumiyet hükümleri kurulması” hukuka aykırıdır.

Güler ise, azmettiredir. Buna rağmen Esas Mahkemesi, mağdurla aralarında kardeşlik ilişkisi bulunması sebebiyle Güler hakkında TCK, m. 82, f. 1, bent d hükmüne istinaden, yani **kasten öldürme suçunun nitelikli halinden** dolayı cezaya hükmetmiştir.

Buna karşılık, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Güler'in TCK, m. 81 hükmüne istinaden, yani **kasten öldürme suçunun temel şeklinden** dolayı cezalandırılması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuş ve Esas Mahkemesinin hükmünü bu yönü itibarıyla doğru bulmayarak bozmuştur. Daire kararında bu hususla ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir.

“... eylemin "nitelikli kasten öldürme" suçunu oluşturup oluşturmadığı faille göre belirlenir ve bu hal şeriklere sirayet ettirilir. Bu durum, TCK'nın 82. maddesinde sayılan tüm nitelikli haller için geçerlidir. Örneğin; A kendi babasını öldürmesi için F'yi azmettirdiğinde, suçun gerçekleşmesi halinde, her ikisi de 81. madde uyarınca sorumlu olurlar. Çünkü failin işlediği suç "basit kasten öldürme" suçudur. Aksine, F'nin, A'yı, A'nın babasının öldürülmesine azmettirdiği durumda ise, hem A'nın, hem de F'nin "82/1-d" maddesi uyarınca nitelikli hallerden olan "yakın akrabayı kasten öldürme suçundan" sorumlu tutulması gerekir. Zira failin işlediği suç "nitelikli öldürme"dir. Azmettiren ise, azmettirirken failin bu suçu işleyeceğini bilmektedir, A'nın babasını, A ile F'nin birlikte öldürmeleri haline gelince; bu durumda ikisi de müşterek fail olacaklarından, A nitelikli kasten öldürmeden, B ise basit kasten öldürmeden cezalandırılmalıdır.”

Halime'ye karşı işlenen kasten öldürme suçunun faili ise, kızı Güler'dir. Halime ile arasındaki üst soy alt soy ilişkisi dolayısıyla Güler'in TCK, m. 82, f. 1 bent d hükmü gereğince, yani kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden dolayı cezalandırılmıştır. Esas Mahkemesi Halime'nin öldürülmesi fiilinden dolayı Cemile'yi sorumlu tutmamıştır. Daire de bu hususu bozma sebebi olarak değerlendirmemiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 1. Ceza Dairesi'nin, Ali Kemal'e karşı işlenen kasten öldürme suçu bağlamında Güler hakkında TCK, m. 81 hükmüne istinaden cezaya hükmedilmesi gerektiği yönündeki kabulüne istinaden verdiği bozma kararına itiraz etmiştir.

Bu itiraza ilişkin olarak şu gerekçeler ileri sürülmüştür:

“765 sayılı TCK'nın 66 ve 67. maddelerinde şahsa ve fiile bağlı kişisel nedenlerin geçişi sorunu konusu düzenlendiği halde, 5237 sayılı TCK'nın 40. maddesinde bu konuda bir hüküm yer almamaktadır. Bu konuda bir hüküm öngörülmemesi unutkanlıktan kaynaklanmamaktadır. Kanun koyucu, bağlılık kuralına ilişkin hükümlerin bu sorunlara cevap verdiği düşüncesiyle bu konuda bir düzenleme yapmayı gereksiz görmüştür. Kanun koyucuya göre, “bu hükümler, bağlılık kuralının henüz bilinmediği 19. yüzyıl ceza hukuku düşüncesinin ürünü olarak kanuna konmuştur. Bağlı-

lık kuralına metinde yer verildikten sonra, bu hükümlerin korunmasına gerek kalmamıştır” (5237 sayılı TCK.nun 40. madde gerekçesi).

Bağlılık kuralı, bir suçtan sorumlu tutulabilmek için suçun kanuni tanımına göre gerekli koşulların bulunmaması halinde, bu koşulların yerine ikame edilmekte ve böylece, eylemleri suçun kanuni tanımına uymayan, yardım eden ve azmettiren gibi şeriklerin cezalandırılmasının temelini oluşturmaktadır. Ancak, bağlılık kuralı, en azından TCK’nın 40. maddesinde yer alan düzenleme, iştirak halinde işlenen suçlarda cezayı ağırlaştırıcı veya hafifletici nitelikli hallerin diğer suç ortakları hakkında uygulanmasına ilişkin bir hüküm öngörmemektedir.

Oysa, bağlılık kuralına yer verilen Alman Ceza Kanununda da ayrıca nitelikli hallerin suç ortaklarına geçişine ilişkin hükümlere yer verilmesi ihtiyacı duyulmuştur (Alman CK 28/2 md). Böylece, bağlılık kuralının suç ortaklarından kaynaklanan kişisel nitelikli hallerin sirayeti sorununu çözmediği kabul edilmiştir. Alman Ceza Kanunun 28/2 maddesinde; “kanun, cezanın ağırlaştırılmasını, indirilmesini veya ortadan kaldırılmasını gerektiren kişisel nitelikli özel unsurlara yer vermiş ise, bunlar yalnızca kendisinde bu neden bulunan suça iştirak edenler (fail veya suç ortakları) hakkında uygulanır” denilerek, (ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, M.Ruhan, Uygulamalı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2011, s. 347, dipnot.1306.) kişisel nitelikli hallerin sirayetine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 5237 sayılı TCK’da, Alman Ceza Kanununda olduğu gibi, kişisel nitelikli hallerin sirayetine ilişkin bir hüküm öngörülmediğine göre, sorunun ceza hukukunun genel ilkelerine göre çözülmesi lazımdır. Cezanın ağırlaştırılması ve hafifletilmesi sonucunu doğuran nitelikli hallerin diğer suç ortakları hakkında uygulanmasının mümkün olup olmadığı sorununa çözüm aranırken aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

1) Ceza hukukunda objektif sorumluluk kabul edilmediğinden, herkes kendi fiilinden sorumlu olacaktır. Ceza hukukundaki, kusursuz ceza olmaz ilkesi uyarınca, kişi, ancak kusurlu fiilinden sorumlu tutulabilir. Ayrıca bu ilke uyarınca kişi ancak kendi kusuru kadar sorumlu tutulabilecektir.

2) Ceza kanununda kanunilik ilkesi cezayı ağırlaştırıcı nitelikli haller bakımından da geçerlidir. O nedenle, fiile ilişkin olmayıp, suç ortaklarından birine ilişkin kişisel bir nedenle cezanın ağırlaşması sonucunu doğuran bir nitelikli halin diğer suç ortaklarına yüklenebilmesi için bu hususun kanunda açıkça yazılı olması lazımdır.

3) TCK’nın 61/son maddesi uyarınca, kanunda açıkça yazılmadıkça, cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir.

Bu genel açıklamalardan sonra konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. (A) isimli bayanın, sevgilisi (B)’yi kendi babasını (A’nın babasını) öl-

dürmesi için teşvik ettiğini düşünelim. Bu olayda (A)'nın sorumluluğuna gidilebilmesi için (B)'nin (A)'nın babasını öldürmesi veya bu suça teşebbüs etmesi gerekli ise de bu durum, suç işlendikten (A)'nın kişisel durumunun dikkate alınmamasını gerektirmez. Bu durum, bağlılık kuralı uyarınca suçun, suç ortakları bakımından aynı olması gerektiği şeklindeki kuralı da ihlal etmez. Gerçekten, suç, fail ve şerik bakımından da öldürme suçu olup, suç aynıdır; (A)'nın şahsından kaynaklanan cezayı ağırlaştıran bir nedenin varlığı bu durumda bir değişiklik yaratmaz. Esasen bu durum, 82/1-d maddesinde yer alıp cezanın ağırlaşması sonucunu doğuran nitelikli halin kabul edilmesindeki amaç ile de çelişir. Kanun koyucu, fiilin haksızlık içeriği, failin tehlikeliliği bakımından daha ağır bir fiil olarak kabul ettiği içindir ki, bu hal bakımından daha ağır bir yaptırım öngörmüştür. Suçu fail olarak gerçekleştirmek bakımından nitelikli halin gerektirdiği ceza tayin edilmesine rağmen, bu suça iştirak etmek bakımından temel halinden ceza tayin edilmesini izah etmek güçtür. Örneğimizdeki olayda (A)'nın niteliksiz adam öldürmek suçuna yardım etmekten sorumlu tutulması, kişinin kendi eyleminden sorumlu olması gerektiği şeklindeki kural ile de çelişir. Gerçekten, bu olayda (A)'nın fiili, babasını öldürmeye teşvik etmektir. Kaldı ki 5237 sayılı TCK'nın 61/10. maddesine göre, kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltiler, ne de değiştirilebilir. Fail ile mağdur arasındaki kişisel ilişki cezanın ağırlaştırılması sonucunu doğuran bir nitelikli hal kabul edilmesine rağmen, bu nitelikli halin suç ortağı hakkında uygulanmaması, ona kanunda yazılı olmayan bir ceza muafiyeti sağlamak anlamına gelir. Bu şekilde bir uygulama kusur ilkesine de aykırı olur. Ceza hukukunda sorumluluk kusura dayanmakta olup, suça iştirak eden her kişi de kusuru oranında sorumlu olur. TCK'nın 40/1 maddesindeki her bir suç ortağının kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır şeklindeki hüküm, yalnızca kişisel cezasızlık nedenleriyle ilişkili gibi görünse de cezayı ağırlaştıran veya hafifleten nitelikli haller bakımından da geçerlidir.

İnceleme konumuz olan olayda da; Güler'in eylemi, kardeşi olan Ali Kemal'i öldürmeye azmettirmektir; o nedenle TCK'nın 38/2 ve 82/1-d maddesi uyarınca cezalandırılmalıdır. Sanık Güler'in niteliksiz adam öldürme suçuna azmettirmekten sorumlu tutulması, kendisine kanunda yer almayan bir ceza muafiyeti sağlamak anlamına gelir. ...

Türk Ceza Kanununa göre, suç ortakları hakkında ne şekilde ceza tayin edilmesi gerektiğine ilişkin görüşümüzü belirtmeden önce bağlılık kuralına esin kaynağı olduğunu düşündüğümüz Alman Ceza Kanunu ve Alman Hukuku bakımından sorunun ne şekilde çözümlendiğini incelemekte fayda bulunmaktadır. Alman Ceza Kanunu'nun 28/1. maddesinde, failin sorumluluğuna yol açan kişisel özellikler şeriklerde mevcut değilse ceza-

larının 49/1 maddesine göre indirim tabi tutulacağı belirtilmektedir. 28/2 maddesinde de, “kanun, cezanın ağırlaştırılmasını, indirilmesini veya ortadan kaldırılmasını gerektiren kişisel nitelikli özel unsurlara yer vermiş ise, bunlar yalnızca kendisinde bu neden bulunan suça iştirak edenler (fail veya suç ortakları) hakkında uygulanır” denilmektedir.

Şeriklerin cezalandırılabilmesi için failin fiili gerçekleştirmesi gerekli ise de, yukarıda da belirtildiği üzere bundan, suça azmettirme veya yardım etme şeklindeki iştirakin değerinin bulunmadığı sonucu çıkarılamaz. Şeriklerin cezalandırılmasının nedeni, suça iştirak iradesiyle katılmaları ve fail veya faillerin hukuka aykırı eylemlerine nedensel değeri de olan hareketlerle destek olmaları ve bu konuda bizzat kusurlu olmalarıdır. Özetle, şerikler hakkında uygulanacak hükümler tespit edilirken kendi kusurları ve kişisel durumları da dikkate alınacaktır; bağlılık kuralı buna engel bir hüküm taşımamaktadır. Kaldı ki TCK’nın 40/1 maddesinde de herkesin kendi kusuruna göre sorumlu tutulacağı belirtilmektedir. Alman Ceza Kanunun 27/2 maddesine göre, yardım edenlerin cezası fail için öngörülen ceza dikkate alınarak tespit edilecektir. Azmettirenlerin ise, sanki kendileri failmiş gibi cezalandırılacakları belirtilmektedir (Alman Ceza Kanunu 26 md). Kanunumuzda gerek yardım edenin, gerekse de azmettirenin “işlenen suçun cezası” ile cezalandırılacağı belirtilmektedir (TCK 38/1, 39/1 md). Suç kavramı, hem suçun temel şeklini, hem de suçun nitelikli halini kapsamaktadır. Kanunumuzda, şeriklerin fail için öngörülen ceza ile cezalandırılacağı şeklinde bir ifade yer almayıp, “işlenen suçun cezası” ile cezalandırılacakları belirtildiğine göre, şeriklere ceza tayin edilirken failin cezası ölçü olarak alınmayacaktır. Diğer bir ifadeyle Kanunumuz, şeriklerin sorumluluğu yoluna gidilebilmesi için fail tarafından suçun kanuni tanımında yer alan fiilin gerçekleştirilmiş olmasını aramakla beraber, suça katılanların cezasını asli faile bağlı tutmamıştır. Zira “işlenen suçun cezası”, “faile verilecek ceza” ile aynı anlama sahip değildir. Failin sıfatı, mağdurla olan ilişkileri nedeniyle faile daha ağır veya daha hafif bir ceza verilmesi mümkündür. Eğer kanun maddesinde, suç ortaklarının faile verilecek ceza ile cezalandırılacakları belirtilmiş olsaydı, cezanın hafifletilmesi veya ağırlaştırılması sonucunu doğuran bu haller şerikler bakımından da geçerli olacak ve onlara da faile verilecek ceza tayin olunacaktı. Ancak Kanunumuz, şeriklere, “faile verilecek ceza” yerine, “işlenen suçun cezası”nın verilmesini tercih etmiştir. Bundan anlaşılması gereken şudur: Eğer şerik bizzat kendisi fail olarak suç işlemiş olsaydı kendisine ne ceza tayin edilmesi gerekli idi ise o ceza tayin edilecektir. Elbette ki şerik olarak suça katıldığı için kanunun öngördüğü oranlarda cezası bir indirim tabi tutulacaktır. Bundan çıkan bir başka sonuç da, fiile bağlı nedenlerin bilmeleri koşuluyla suç ortaklarına sirayet etmesi, kişisel nedenlerin ise sirayet etmemesidir. Fakat kanun koyucu elbette ki bu konuda farklı bir düzenleme yoluna gidebilir ve fiili ve kişisel nedenlerin sirayeti konusunda hükümler öngörebilir. Örneğin 765 sayılı

TCK'nın 66 ve 67. maddelerinde bu konuda düzenleme yapılmıştı. Ancak 5237 sayılı TCK'da bu konuda bir düzenleme yapılmadığına göre, fiili nedenlerin bütün suç ortakları bakımından geçerli olduğunu -çünkü bu nedenler suça ilişkindir ve suç ortaklarının iradesinin kapsamındadırlar- ancak kişisel nedenlerin de kendisinde bu nedenler bulunan kişiler bakımından uygulanacağını kabul etmek gerekir.

Kısaca tekrarlamak gerekirse, azmettiren kaynaklanan kişisel nedenler cezasının belirlenmesinde dikkate alınacak, kendisi fail olarak suçu işleyeydi hangi hükümlere göre cezalandırılacak idi ise cezası o şekilde tespit edilecektir. Buna göre Güler'in TCK'nın 38/2 ve 82/1-d maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine 38/2, 81 maddesi hükümleri uyarınca cezalandırılması gerektiğine ilişkin Özel Dairenin bozma kararında isabet bulunmamaktadır.”

Ancak 1. Ceza Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu itirazının reddine ve “dosyanın itiraz konusunda karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine” karar vermiştir (17.09.2014).

Yargıtay Ceza Genel Kurulu söz konusu itirazı usulden reddetmiştir¹²²⁸. Ancak bu usulden ret kararında, 1. Ceza Dairesinin bağlık kuralına ilişkin bozma gerekçelerinin soyut bir şekilde “*öğretici ve yol gösterici mahiyette ol*”duğu değerlendirilmesinde bulunmuştur.

Hukuki değerlendirmelerimiz:

Söz konusu itiraz gerekçesinde önemli çelişkiler bulunmaktadır.

I. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bağlık kuralı ile ilgili olarak Alman Ceza Kanununda yeni TCK'nın 40. maddesinde düzenlenen içerikte hüküm bulunmamaktadır.

Alman Ceza Kanununda bulunan hükümler, 19. yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir yansıması olan eski hükümlerdir. Bu hükümlerle mülga 765 sayılı TCK'nın 66 ve 67. maddeleri hükümleri arasında benzerlik bulunmaktadır. Alman Ceza Kanununda yer alan ibare, “**Cezanın artırılmasını, cezada indirim yapılmasını veya ceza verilmemesini gerektiren özel kişisel özellikler**” ibaresidir. Hem belirtelim ki, bu ibare kapsamında, hem gerçek özgü suçlardaki özel faillik vasfı, hem failin şahsından kaynaklanan ve suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az ceza verilmesini gerekli kılan nitelikli unsurlar, hem de şahsi cezasızlık sebeplerini veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepleri değerlendirme konusu yapılmıştır. Oysa bütün bu kavramların içerikleri ve mahiyetleri arasında önemli farklar bulunmaktadır.

¹²²⁸ CGK, 24.5.2016, E. 2014/1-593, K. 2016/269.

§28, f. 1’deki “**özel kişisel hususiyetler**” (“besondere persönliche Merkmale”) ibaresi, özgü suçlardaki özel faillik vasfına tekabül etmektedir. Örneğin **görevi kötüye kullanma** ve **zimmet** suçlarında (TCK, m. 257, 247) failin **kamu görevlisi** olması; **fırar** suçunda¹²²⁹ failin **asker kişi, askeri şahıs** olması, §28, f. 1 anlamında “**özel kişisel hususiyet**”tir. “Özel kişisel hususiyet”in arandığı bir suçta bu hususiyeti taşımayan bir kişinin iştirak etmesi halinde, §28, f. 1 bu kişinin cezalandırılabilmesinin dayanağını oluşturmaktadır¹²³⁰. Başka bir ifadeyle, söz konusu hüküm, **gerçek özgü suçlarda**, özel faillik vasfını taşımayan kişilerin suçun işlenişine iştirak etmesi hali ile ilgili bağlılık kuralını içermektedir¹²³¹. Bu yönü itibarıyla Alman Ceza Kanunu §28, f. 1 ile TCK, m. 40, f. 2 arasında bir müştereklik bulunmaktadır. Ancak, söz konusu hükme göre bu durumda özel faillik vasfını taşımayan azmettiren veya yardım edenin cezasında §49, f. 1 hükmüne istinaden indirim yapılması gerekmektedir. Bu yönü itibarıyla Alman Ceza Kanunu §28, f. 1 ile TCK, m. 40, f. 2 arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır.

Buna karşılık, § 28, f. 2’de ise, cezayı artıran, azaltan veya ceza verilmesine mani “özel kişisel hususiyetler”e ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- 1) cezayı artıran “özel kişisel hususiyetler”.
- 2) cezayı azaltan “özel kişisel hususiyetler”.
- 3) ceza verilmesine mani “özel kişisel hususiyetler”.

§ 28, f. 1’den farklı olarak, § 28, f 2’de ise, cezayı artıran, azaltan veya ceza verilmesine mani “özel kişisel hususiyetler”in diğer suç ortaklarına **sirayetini engelleyen** bir hükme yer verilmiştir. Bu yönü itibarıyla, § 28, f 2 hükmü, bağlılık kuralının istisnasını oluşturmaktadır, **bağlılık kuralının uygulanamayacağı durumlara** ilişkin bir düzenleme içermektedir¹²³².

Türk ceza hukuku doktrininde, bu farklar göz ardı edilerek, bağlılık kuralına getirilmeye çalışılan açıklamalarda ciddi tutarsızlıklar mevcuttur. Önemle belirtmelidir ki, şahsi cezasızlık sebepleri veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler, işlenen fiilin haksızlık muhtevasında bir değişiklik meydana getirmediği için, ister fail olsun ister şerik (azmettiren veya yardım eden) olsun, sadece ilgili suç ortağı bakımından dikkate alınabilir. Nitekim TCK’nın 40. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, “**Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır**” hükmüne yer

¹²²⁹ 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı **Askeri Ceza Kanunu**, m. 66, 67.

¹²³⁰ GROPP, Walter: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, Berlin, Heidelberg, 2015, § 10, kn. 244.

¹²³¹ GROPP, Allgemeiner Teil (4), § 10, kn. 244.

¹²³² GROPP, Allgemeiner Teil (4), § 10, kn. 245.

verilmiştir. Bu hükümle bağlantılı olarak madde gerekçesinde “cezayı hafifleten veya ortadan kaldıran kişisel nedenler, ancak ilgili suç ortağı açısından hukukî sonuç doğururlar” açıklamasına yer verilmiştir.

Örneğin, A, B ile birlikte A’nın kardeşi C’nin işyerinden hırsızlık yapar. A ile C arasında kardeşlik ilişkisinin bulunması, cezada indirim yapılmasını gerektiren bir şahsi sebeptir (TCK, m. 167, f. 2). A ve B, bu suçun işlenmesi bakımından müşterek faildirler. B, A ile C’nin kardeş olduğunu bilsin veya bilmesin, TCK, m. 167, f. 2 hükmünden A yararlanabilecek ise de, B yararlanamayacaktır.

B’nin, bu suçu işlemeye A’yı azmettirmiş veya bu suçun işlenmesinde A’ya yardım etmiş olması hallerinde de durum değişmeyecektir. Bu gibi durumlarda, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepten sadece A yararlanacaktır, azmettiren veya yardım eden olarak B’nin cezasında bu sebeple herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

Buna karşılık, failin vasfının veya faille mağdur arasındaki ilişkinin işlenen suçun haksızlık muhtevası üzerinde etkili olması halinde farklı bir yöntem izlemek gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, cezayı artıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep değil, suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli unsuru söz konusudur.

II. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin zikredilen Kararına konu teşkil eden olayda Ali Kemal’e karşı kasten öldürme suçunu Cemile işlemiştir. Suçun faili Cemile’dir. Cemile bakımından söz konusu olayda, ancak TCK’nın 81. maddesi hükmüne istinaden, yani kasten öldürme suçunun temel şeklinden dolayı mahkumiyet hükmü kurulabilir.

Güler ise, Ali Kemal’e karşı işlenen kasten öldürme suçunun hem azmettireni hem de yardım edenidir. Güler, azmettiredir; çünkü suç işleme fikri olmayan Cemile’nin Ali Kemal’i öldürmesi konusunda düşünceye ve karara varmasını sağlamıştır. Güler aynı zamanda yardım edendir; çünkü Cemile’nin işlediği kasten öldürme suçunda silahı temin etmiştir yani, fiilin işlenmesinde kullanılan aracı sağlamıştır (TCK, m. 39, f. 2, bent b).

Güler’in azmettiren sıfatıyla sorumluluğu cihetine gidebilmek için, suçun işlenmesi hususundaki inisiyatifi Cemile’ye havale etmesi gerekir. Şayet Güler, Cemile’yi azmettirmenin ve suçu işlemekte ihtiyaç duyulan silahı temin etmenin yanı sıra, Cemile’yi yönlendirerek fiilin işlenişinde Cemile ile birlikte müşterek hakimiyet tesis etmiş ise, azmettiren olarak değil, müşterek fail olarak sorumlu tutulmalıdır. Karara konu teşkil eden olayda Güler, Cemile’nin kasten öldürme suçunun icra hareketlerini gerçekleştirdiği sırada olay mahallindedir ve Cemile’yi yönlendirmektedir. Başka bir ifadeyle, suçun işlenişini Cemile’nin inisiyatifine havale etmemiştir. Bu nedenle Ali Kemal’e karşı işlenen kasten öldürme suçu bakımından Güler ve Cemile’yi **müşterek fail** olarak sorumlu tutmak gerekir.

Güler ile Ali Kemal kardeşler. Bu nedenle Güler'in TCK, m. 82, f. 1, bent d hükmüne istinaden, yani **kasten öldürme suçunun nitelikli halinden** dolayı cezalandırılması gerekir. Buna karşılık Cemile'nin ise, TCK, m. 81 hükmüne istinaden, yani **kasten öldürme suçunun temel şekli** esas alınarak cezalandırılması gerekir. Cemile, Ali Kemal ile Güler arasında kardeşlik ilişkisinin olduğunu bilse bile, kasten öldürme suçunun temel şeklinden dolayı cezalandırılması gerekir.

Oysa mülga 765 sayılı TCK'nın 67. maddesine göre, bu durumda Cemile'nin de, "vukuf şartı"na bağlı olarak, kasten öldürme suçunun nitelikli halinden dolayı cezalandırılması gerekmekte idi.

Güler'in Cemile ile birlikte suçun işlenişi üzerinde müşterek hakimiyet tesis edememiş/etmemiş olması halinde ise, suçun faili Cemile olduğu için, Cemile'nin fail sıfatıyla işlediği kasten öldürme suçundan (TCK, m. 81) dolayı Güler'i azmettiren sıfatıyla cezalandırmak gerekir. Zira TCK, m. 38, f. 1'e göre, "**Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun (kanundaki) cezası ile cezalandırılır.**" İşlenen suç, fail bakımından kasten öldürme suçunun temel şeklidir. Bu nedenle, Cemile'nin de **suçun temel şekli** esas alınarak cezalandırılması gerekir¹²³³.

¹²³³ Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 25.6.2014 tarihli ve E. 2013/3531, K: 2014/3655 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda Muhammet ile evli olan Elem müşterek ikamet ettikleri evi terk edip Önder ile birlikte gayri ahlaki bir hayat sürmeye başlar. Bunun üzerine Muhammet, Murat'ın sevk ve idaresindeki araçla yanlarında Kenan ve Sinan olduğu halde, Önder'in sevk ve idaresindeki aracı takip ederler. Önder'in aracında Elem ve Leyla da bulunmaktadır. Önder'in aracının durduğu bir anda, Muhammet ve arkadaşları araçtan inerek Önder'in aracına yönelirler. Muhammet elindeki tabancayla Önder'i önce tehdit ederek ve bilahare yaralayarak karşı koymaz hale getirir. Murat, Kenan ve Sinan ise, Elem'i sürükleyerek kendi araçlarına bindirirler. Bu sırada Leyla, bağırarak yardım ister. Muhammet, ses çıkarmaması için Leyla'yı önce tehdit eder ve bilahare tabancasıyla yaralar. Olay yerinden ayrılan ve Murat'ın sevk ve idaresindeki araç yolda seyir halinde iken, Elem, Muhammet'e hakaret eder. Bunun üzerine, Muhammet, tabancayla ateş ederek Elem'i öldürür.

Bu olayla ilgili olarak Daire şu kararı vermiştir:

"Mülga 765 sayılı TCK'nın 66 ve 67. maddelerinde düzenlenen "şahsi ya da fiili ağırlaştırıcı sebeplerin sirayeti hükümlerine (5237 s. TCK'da) yer verilmemiştir. (Bu durum karşısında), şahsa bağlı sebeplerden **yalnızca ilgilisi** yararlanabilecektir. Şahsa bağlı sebeplerin cezaı artırdığı durumlarda da aynı uygulama yapılacaktır.

Müşterek fail(likte) suçu birlikte işleyen failler, kendi fiillerine göre cezalandırılırlar. Zira, müşterek faillerin her birinin fiili haksızlık niteliğini kendi fiilinden alır ve diğerine bağlılık arz etmez. Bu nedenle, **müşterek faillerden birisinde bulunan nitelikli hal, diğerleri tarafından bilinse de onu etkilemez.**

Buna karşılık, şeriklerin sorumluluğu doğrudan değildir, şerikler, suçtan bağlılık kuralı gereğince sorumlu tutulurlar. Başka bir anlatımla, şeriklerin suçla irtibatları failin şahsına ve işlediği fiile bağlılık arz etmektedir. Bu nedenle, şerikler kendilerince bilinen ve failin işlediği fiilden veya şahsından kaynaklanan nitelikli hallerden etkilenirler.

Sonuç olarak; ister fiilden, isterse failin veya mağdurun şahsından ya da özelliklerinden kaynaklanmış olsun, eylemin "nitelikli kasten öldürme" suçunu oluşturup oluşturmadığı faille göre belirlenir ve bu hal şeriklere sirayet ettirilir. Bu durum, TCK'nın 82. maddesinde sayılan tüm nitelikli haller için geçerlidir. Örneğin, A kendi babasını öldürmesi için F'ye yardım ettiğinde,

Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu itirazına ilişkin gerekçelerde tutarlılık bulunmamaktadır. Aşağıdaki örnek olaylara ilişkin değerlendirmelerimiz, bağlilik kuralına ilişkin açıklamalarımızı daha anlaşılır kılacaktır:

Örnek olay 1. TCK'nın 104. maddesinde, reşit kişinin, onbeş yaşını bitirmiş olmakla birlikte henüz reşit olmayan kişiyle rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, TCK, henüz reşit olmayan kişinin cinsel ilişkiye yönelik rıza açıklamasına hukuki değer tanımamıştır. Ancak bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı kılınmıştır. Buna karşılık, fail ile mağdur arasında evlenme yasağının bulunması halinde, hem suçun cezası artırılmakta hem de soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olmaktan çıkmaktadır (m. 104, f. 2).

Birinci ihtimal: B'nin azmettirmesi üzerine, reşit olan A, onbeş yaşını bitirmiş olmakla birlikte henüz reşit olmayan kardeşi C ile rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girer. Bu durumda A hakkında TCK, m. 104, f. 2 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekecektir. Keza, C ile arasında kardeşlik ilişkisi bulunmasa bile, azmettiren sıfatıyla B hakkında da TCK, m. 104, f. 2 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekecektir. B'nin azmettiren değil de yardım eden olması halinde de durum değişmeyecektir.

İkinci ihtimal: A'nın azmettirmesi üzerine, reşit olan B, A'nın onbeş yaşını bitirmiş olmakla birlikte henüz reşit olmayan kardeşi C ile rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girer. Bu durumda ise, B hakkında ancak şikayet üzerine TCK, m. 104, f. 1 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekecektir. Keza, C ile arasında kardeşlik ilişkisi bulunmasına rağmen, azmettiren sıfatıyla A hakkında da TCK, m. 104, f. 1 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekecektir.

Örnek olay 2. A, C ile evlenmesini sağlamak amacıyla D'yi kaçırmaları için, B ve C'yi, azmettirir. B ve C de, müşterek failer olarak, D'yi kaçırmaları.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından cinsel arzuların tatmini amacı, suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurdur. İştirak

suçun gerçekleşmesi halinde, her ikisi de 81. madde uyarınca sorumlu olurlar. Çünkü failin işlediği suç "basit kasten öldürme" suçudur. Aksine, F'nin, A'nın kendi babasını öldürmesine yardım ettiği durumda ise, hem A'nın, hem de F'nin "82/1-d" maddesi uyarınca nitelikli hallerden olan "yakın akrabayı kasten öldürme suçundan" sorumlu tutulması gerekir. Zira failin işlediği suç "nitelikli öldürme"dir. Yardım eden ise, yardım ederken failin bu suçu işleyeceğini bilmektedir. A'nın babasını, A ile F'nin birlikte öldürmeleri haline gelince; "bağlilik kuralı uyarınca değil" bizzat 37. madde uyarınca her ikisi de müşterek fail olacaklarından, (A) **nitelikli kasten öldürmeden**, (B) **basit kasten öldürmeden** cezalandırılmalıdır.

Buna göre somut olayda; Murat ve Kenan'ın, maktule ile sanık Muhammet'in evli olduğunu bildikleri halde sanık Muhammet'in "eşini kasten öldürme" suçuna **yardım ettikleri** anlaşılmakla, TCK'nın 82/1-d ve 39. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları yerine bağlilik kuralına yanlış anlam verilmek suretiyle kasten öldürme suçuna yardımdan, TCK'nın 81,39 maddeleri uyarınca hüküm kurulması, ... Yasaya aykırı"dır.

halinde işlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun failinin bu amaçla hareket etmesi gerekir ki, TCK, m. 109, f. 5 hükmüne istinaden cezalandırılması yoluna gidilebilsin. Bu nitelikli unsurun varlığı için cinsel arzuları tatmin edilmesi amaçlanan kişinin önemi yoktur. Cinsel arzuları tatmin edilmesi amaçlanan kişi, fail olabileceği gibi, şerik ve hatta suça iştirak etmemiş olan sair bir kişi de olabilir.

Failin cinsel amaçla hareket etmesine rağmen, diğer suç ortaklarının, şeriklerin bu amaçla hareket etmemesi, yani failin böyle bir amaçla hareket ettiğini bilmemesi halinde, faili, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halinden dolayı, TCK, m. 109, f. 5 hükmüne istinaden cezalandırmak gerekir. Buna karşılık, failin böyle bir amaçla hareket ettiğini bilmeyen ve dolayısıyla, cinsel arzuların tatmini amacıyla hareket etmeyen diğer suç ortaklarının ceza sorumluluğu belirlenirken, söz konusu beşinci fıkra hükmü dikkate alınmaz (TCK, m. 21, f. 1; m. 30, f. 2).

Aynı değerlendirmeyi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde de dikkate almak gerekir. Bu durumda söz konusu suçu birlikte işleyenlerin hepsi, **müşterek faildirler**¹²³⁴. Müşterek faillerden birinin cinsel amaçla hareket etmesine rağmen, diğer müşterek failin veya faillerin bu amaçla hareket etmemesi halinde, yani suç ortaklarından birinin bu amaçla hareket ettiğini bilmemesi halinde, bu müşterek faillerden birincisi hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halinden dolayı, TCK, m. 109, f. 5 hükmüne istinaden cezaya hükmetmek gerekir. Buna karşılık, birinci müşterek failin böyle bir amaçla hareket ettiğini bilmeyen diğer müşterek faillerin ceza sorumluluğu belirlenirken, söz konusu beşinci fıkra hükmünün dikkate alınmaması gerekir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cinsel amaçla işlenmesi, bu suçun nitelikli halinden dolayı, TCK, m. 109, f. 5 hükmüne istinaden cezalandırılmayı gerekli kılmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu nitelikli unsurun varlığı için cinsel arzuları tatmin edilmesi amaçlanan kişinin önemi yoktur. Cinsel arzuları tatmin edilmesi amaçlanan kişi, fail, şerik (azmettiren veya yardım eden) ve hatta suça iştirak etmemiş olan sair bir kişi de olabilir. Bu suç ortaklarından herhangi birinin bu amaçla hareket etmesi ve diğer suç ortaklarının bu durumdan haberdar olması, bu suçun nitelikli halinden dolayı, TCK, m. 109, f. 5 hükmüne istinaden cezalandırılmaları için gerekli ve yeterlidir.

Örnek olay 3. A, on dört yaşında olan B'ye karşı cinsel istismar suçunu (TCK, m. 103) işler. B, hamile kalır. A, işlediği suçun ortaya çıkacağı endişesiyle, B'yi öldürmeye karar verir. A, B'nin öldürülmesi için ihtiyaç duyduğu silahı, C'den temin eder. C, A'nın B'yi öldürmeye karar verdiğini bilmektedir ve bu kasıtlı silahı temin eder. Ancak C, A'nın B'ye karşı daha önce cinsel istismar suçunu işlediğini, bu suçtan B'nin hamile kaldığını ve bu suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla hareket ettiğini bilmemektedir.

¹²³⁴ Bkz. TCK'nın TBMM Adalet Komisyonu tarafından düzenlenen 109. maddesi gerekçesi.

Bu örnek olayda kasten öldürme suçunun faili olan A, daha önce işlemiş olduğu cinsel istismar suçunu gizlemek, bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla hareket ettiği için, kasten öldürme suçunun nitelikli halinden dolayı, TCK, m. 82, f. 1, bent h hükmüne istinaden cezalandırılacaktır. Buna karşılık, C ise, daha önce işlenmiş olan cinsel istismar suçundan ve dolayısıyla, A'nın amacından haberdar olmadığı için, kasten öldürme suçunun temel şeklinden dolayı (TCK, m. 81) yardım eden sıfatıyla cezalandırılacaktır.

Örnek olay 4. A, C'den alacağını hukuk yollarına başvurarak tahsil edemez; bu sebeple, B ile birlikte C'ye cebir uygulayarak alacağı tahsil ederler. Bu örnek olayda, alacaklı olan kişinin, A'nın alacağını tahsil amacıyla borçluya cebir veya tehdit uygulamış olması halinde, TCK, m. 150, f. 1 hükmünden yararlanacağına kuşku yoktur.

Ancak, A'nın alacağının tahsili amacıyla ve onunla birlikte C'ye cebir uygulayan B, TCK, m. 150, f. 1 hükmünden yararlandırılmaz. Bu gibi durumlarda gerçekten alacaklı olan kişi (A) ile birlikte hareket eden B de, kendi alacağı olmasa bile, aynı amaçla hareket edebilir. Ancak, m. 150, f. 1 ifadesine göre, alacağın failin kendisine ait olması gerekmektedir. Bu nedenle, müşterek faillerden sadece A bakımından TCK, m. 150, f. 1 hükmünü uygulamak gerekir¹²³⁵.

Keza, A, C'den hukuk yollarına başvurarak tahsil edemediği alacağını tahsil hususunda B ile belli bir "komisyon" karşılığında ve gerektiğinde çeşitli zorlama yöntemlerine başvurulacağı öngörüsüyle ve zımni kabulüyle anlaşır. B de bunun üzerine, cebir ve tehdit kullanarak C'den alacağı tahsil eder.

¹²³⁵ Kitabımın 13. basısında bu bağlamda farklı açıklamaya yer vermiş olmakla birlikte, Sayın Mahmut KOCA'nın uyarısı üzerine bu açıklamalarımı revize etmiş bulunmaktayım. Bu itibarla, Yargıtay 1.CD'nin **26.06.2013** tarihli ve E. 2013/1636, K. 2013/4670 sayılı Kararındaki bozma gerekçesini **doğru** bulmaktayım. Bu Karara konu teşkil eden olayda, Mehmet ve Cengizhan, Oktay'ı öldürürler.

Esas mahkemesi bu olayda Mehmet ve Cengizhan'ı kasten öldürme suçunu tasarlayarak ve kan gütme saikiyle işlemiş olması sebebiyle mahkum etmiştir.

Buna karşılık Daire, Mehmet ile öldürülen arasında husumet bulunmaması sebebiyle, her ne kadar Cengizhan'ın kan gütme saikiyle hareket ettiğini bilmekte ise de, Mehmet hakkında kasten öldürme suçunun kan gütme saikiyle işlediğinin kabulüyle hüküm kurulmasını hukuka aykırı bulmuştur.

Ancak belirtmek gerekir ki, Yargıtay **Ceza Genel Kurulu** bu konuda farklı içtihadta bulunmuştur:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **23.5.2017** tarihli ve E. 2017/6-91, K. 2017/291 sayılı kararına konu teşkil eden olayda, Süleyman, noter sözleşmesi olmadan sattığı aracı Fahrettin'e teslim eder. Ancak, Süleyman'ın yetkilisi olduğu şirketin vergi borcu nedeniyle haczedilen araç Fahrettin'in zilyetliğinden alınarak muhafaza altına alınır. Süleyman, vergi borcunu ödeyerek aracı teslim alır; ancak Fahrettin'e iade etmez. Bunun üzerine, Fahrettin, yanında işçi olarak çalışan İsmet ile birlikte zor kullanarak aracı Süleyman'dan teslim alır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu olayda Fahrettin'le birlikte yağma suçunun işlenmesine müşterek fail sıfatıyla iştirak den İsmet hakkında da TCK'nın 150/1. maddesinin uygulanması gerektiği yönünde içtihadta bulunmuştur.

“Çek senet mafyası” gibi bir oluşum çerçevesinde belirli bir yüzde karşılığında gerektiğinde cebir veya tehdit kullanarak tahsilat işi gerçekleştiren kişi (B) hakkında TCK, m. 150, f. 1 hükmüne istinaden değil, TCK, m. 149 hükümlerine istinaden cezaya hükmetmek gerekir. Zira azmettiren (A) alacağını tahsil amacıyla hareket etmiş olsa bile, fail (B), azmettirenin alacaklı olup olmadığına bakmaksızın, paranın tahsil edilebilirliğini ve tahsil karşılığında alacağı payı göz önünde bulundurarak yağma suçunu işlemektedir. Fail, azmettirenin alacağını tahsil amacıyla hareket ettiğini bilse bile, kendi fiili bakımından bu amaç söz konusu olmadığı için, TCK, m. 150 hükümlerinden yararlanamaz.

Keza, paranın tahsil işinin belirli bir komisyon karşılığında bir başkasına havale edilmesi ve havale edilen kişinin de borçluya cebir veya tehdit uygulaması halinde ise, işlenen suç yağma suçu olduğu için, azmettiren de TCK, m. 149 hükümlerine istinaden cezalandırılacaktır.

Örnek olay 5. A, B’yi hamile kaldığı çocuğu düşürmesi için azmettirir ve çocuğu düşürebilmesine yönelik yöntemler konusunda bilgilendirir. Bunun üzerine B, çocuğu düşürür.

Bu örnek olayda suçun faili B’dir. B, kendi hamile kaldığı çocuğu düşürür. Bu durumda B’nin işlediği suç, TCK, m. 100’de tanımlanan “Çocuk düşürme” suçudur. Azmettiren ve aynı zamanda yardım eden konumunda olan A’yı da B tarafından işlenen suça (TCK, m. 100) azmettirmeden dolayı cezalandırmak gerekir.

Çocuk düşürme suçunun failinin hamile kadının kendisinin olması, Alman CK, §28, f. 2’deki “cezayı azaltan özel kişisel hususiyet” olarak değerlendirilmiştir. Türk hukukundan farklı olarak Alman ceza hukuku uygulamasında § 28, f. 2 karşısında A’yı çocuk düşürme suçuna ilişkin hükme göre değil, çocuk düşürme suçuna ilişkin hükme göre cezalandırmak gerekecektir. Çünkü, B’de bulunan “cezayı azaltan özel kişisel hususiyet”, A’da bulunmamaktadır¹²³⁶.

Alman Ceza Kanunu, §29 hükmüne göre, iştirak statüleri itibarıyla cezalandırılabilmesinde suç ortaklarının kusurluluk durumu göz önünde bulundurulmaz. Suç ortaklarının her biri, sadece kendi kusurluluk durumu itibarıyla cezalandırılır: “**Sınırlı bağluluk kuralı**”. Söz konusu kural, TCK, m. 40, f. 1 hükmünün düzenlemesinde de göz önünde bulundurulmuştur (ikinci cümle)¹²³⁷. Bu yönü

¹²³⁶ GROPP, Allgemeiner Teil (4), § 10, kn. 258, 259.

¹²³⁷ “İştirak halinde işlenmiş suçlarda fail, yardım eden veya azmettiren suç ortaklarından birinin mağdurun zararını tamamen gidermesi halinde, artık giderilmesi gereken bir zarar bulunmadığından zararı gidermeyen diğer suç ortakları yönünden etkin pişmanlık müessesesinin uygulanması için “iade ve tazmin” şartı aranmayacaktır. Ancak TCK’nın 168. maddesi tazmin-den çok pişmanlık esasına dayandığından zararı gidermeyen diğer suç ortaklarının en azından pişmanlıklarını ya da iade ve tazmine rıza gösterdiklerini ortaya koyacak söz veya davranışlarda bulunmaları gerekmektedir.”: CGK, 29.3.2016, E. 2015/13-517, K. 2016/154.

itibarıyla Alman ceza hukuku uygulamasıyla TCK, m. 40 düzenlemesi arasında bir müştereklik mevcuttur.

IV. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

Bir suçun işlenişine iştirak eden kişilerin suçun icrasına başladıktan sonra ve fakat henüz icrası tamamlanmadan veya neticesi gerçekleşmeden gönüllü vazgeçmesi mümkündür. Suç ortaklarının hepsinin gönüllü vazgeçmesi halinde, sorun yoktur. Bu durumda ceza sorumluluğu bakımından nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği, TCK'nın 36. maddesinde düzenlenmiştir.

Burada sorun, suçun işlenişine iştirak eden kişilerden sadece bir kısmının gönüllü vazgeçmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumla ilgili olarak yeni TCK'nın 41. maddesinde düzenleme yapılmıştır. Maddenin birinci fıkrasına göre, iştirak ilişkisinin varlığı halinde, “*sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır*”acaktır. Çünkü, gönüllü vazgeçme, **cezayı kaldıran bir şahsi sebep** niteliği taşımaktadır¹²³⁸.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, iştirak statüleri ne olursa olsun, suç ortaklarının işlemeyi kararlaştırdıkları suçun icrasına başlamadan vazgeçmiş olmaları halinde, o ana kadar gerçekleştirdikleri hareketler başka bağımsız bir suç oluşturmadığı takdirde, cezalandırılmaları yoluna gidilemeyecektir. Ancak, bu durumda suç ortaklarının cezalandırılmamasının sebebini TCK'nın gönüllü vazgeçmeye ilişkin 36. maddesi hükmü oluşturmamaktadır. Çünkü, bu durumda işlenmesi kararlaştırılan suçun icra hareketleri henüz başlamış değildir. TCK'nın 36. maddesinde düzenlenen gönüllü vazgeçmeden söz edebilmek için, suçun başlanmış olan icra hareketlerine pişmanlık duyularak devam edilmez veya icra hareketleri bitmiş olmakla birlikte, neticenin gerçekleşmesi engellenir.

Ancak, hazırlık hareketi mahiyetindeki fiil başka bağımsız bir suç oluşturuyorsa, bundan dolayı cezalandırılma yoluna gidilecektir. Örneğin A, B'yi, D'yi öldürmeye azmettirir. C de B'ye D'yi öldürmekte ihtiyaç duyduğu silahı temin eder veya ona D'yi nasıl öldürmesi gerektiği hususunda bilgi verir. Fakat B, bu anlaşmaya rağmen, bilahare suçu işlemekten vazgeçer, yani A ve C'nin haberi olmadığı halde ya da bunların isteğine rağmen, suçun icrasına başlamaktan imtina eder.

Etkin pişmanlık, duruma göre cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren bir şahsi sebeptir. Birden fazla kişinin iştirakiyle işlenen suçlarda suç ortaklarından birinin etkin pişmanlık göstermesi halinde, TCK, m. 40, f. 1, ikinci cümle gereğince, bu etkin pişmanlıktan sadece bu suç ortağı yararlanır. Bu itibarla, somut olayda zararın tazmininin sadece bir suç ortağının karar ve inisiyatifıyla mı, yoksa suç ortaklarının müşterek kararıyla mı gerçekleştiğinin araştırılması gerekir. Burada önemli olan, tazmin amaçlı paranın kimin cebinden çıktığı değil, tazmin yönündeki iradenin oluşumu ve bunun hayata geçirilmesine katkıdır.

¹²³⁸ “persönlicher Strafaufhebungsgrund”: SÖZÜER, Suça Teşebbüs, sh. 240; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 58; JESCHECK, Lehrbuch (4), sh. 494, 498.

Bu örnek olayda, kasten öldürme suçunun icrasına henüz başlanmadığı için, A, B ve C'yi cezalandırmayacağız. Ancak, bu olayda TCK'nın 36. maddesi hükmü uygulanmaz. Çünkü, bu durumda işlenmesi kararlaştırılan kasten öldürme suçunun icra hareketleri henüz başlamış değildir. Bu olayda, hazırlık hareketi olarak o ana kadar gerçekleştirilen hareketler başka bağımsız bir suç oluşturduğu için bu suçtan dolayı cezalandırma yoluna gidilmelidir. Bu itibarla, örnek olayda, bulundurulması suç teşkil eden silahı B'ye veren C'nin fiili ile silahı kabul eden B'nin fiili 6136 s. Kanun hükümlerine göre başka bağımsız bir suç oluşturduğu için, B, C ve hatta, duruma göre A, bu suçtan dolayı cezalandırılmalıdırlar.

TCK'nın 41. maddesindeki gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümlerin ne suretle uygulanacağı, gönüllü vazgeçenin iştirak statüsüne göre izah edilmesi gerekecektir.

Buna göre, müşterek faillerden birisi gönüllü vazgeçerek suçun icrasına devam etmekten vazgeçmiş olabilir. Bu durumda sadece gönüllü vazgeçen müşterek fail, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanacaktır. Müşterek faillerden birinin gönüllü vazgeçmesi dolayısıyla, diğer müşterek failler suçu işleme yönündeki iradelerine rağmen suçun icrasını tamamlayamamış olabilirler. Bu durumda, suçun icrasını tamamlayamamış olan diğer müşterek faillerin işlemeyi kastettikleri suçtan dolayı teşebbüs hükümlerine göre sorumlu tutulması gerekmektedir.

Müşterek faillerden birinin gönüllü vazgeçmesine rağmen diğer müşterek faillerin suçun icrasına devam etmek istemeleri halinde, gönüllü vazgeçen müşterek failin sorumluluğu bakımından iki ihtimal üzerinde özellikle durmak gerekmektedir.

Birinci ihtimalde, müşterek faillerden birisi gönüllü vazgeçmiştir. Ancak, suçun icrası, müşterek faillerden birinin gönüllü vazgeçmiş olması sebebiyle değil de, bir başka sebeple tamamlanamamış olabilir. Müşterek faillerden biri gönüllü vazgeçmiş ve diğer müşterek failleri suçu icradan vazgeçirme yönünde çaba göstermiş olmasına rağmen, diğer müşterek failler suçu işlemek yönündeki iradelerinden vazgeçmemişlerdir. Diğer müşterek failler, gönüllü vazgeçen müşterek failin gönüllü vazgeçmesinin dışında başka bir sebeple örneğin kolluk görevlilerinin müdahalesiyle suçu icra edememiş olabilirler. Bu durumda, suçu işleme yönündeki iradelerinde sebat eden müşterek faillerin işlemeyi kastettikleri suçtan dolayı teşebbüs hükümlerine göre sorumlu tutulması gerekmektedir. Buna karşılık, gönüllü vazgeçen müşterek fail hakkında ise, yeni TCK'nın 41. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu madde **gereğince** bu ihtimalle ilgili olarak şu açıklamaya yer verilmiştir:

“Gönüllü vazgeçen suç ortağı, suçun işlenmemesi için elinden gelen bütün gayreti göstermiş ve fakat, suç başka bir nedenle işlenememiş olabilir. Bu durumda dahi, gönüllü vazgeçen suç ortağını gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlandırmak gerekecektir.”

İkinci ihtimalde ise, müşterek faillerden birisi gönüllü vazgeçmiş ve diğer müşterek failleri suçu icradan vazgeçirme yönünde çaba göstermiş olmasına rağmen

men, diğer müşterek failler suçu işlemek yönündeki iradelerinden vazgeçmemiş ve dolayısıyla, suçun icrası tamamlanmıştır. Yeni TCK'ya göre, bu durumda da, suçun icrasını engelleme yönünde gerekli gayreti sarfetmiş olan, elinden gelen bütün imkanları kullanmış olan müşterek fail, 41. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanabilecektir. Söz konusu madde **gerekçesinde** bu ihtimalle ilgili olarak şu açıklamaya yer verilmiştir:

“Keza, gönüllü vazgeçen suç ortağının bütün gayretine rağmen, diğer suç ortakları suçu işlemiş olabilir. Bu durumda, suçun işlenmiş olmasına rağmen, gönüllü vazgeçen ve suçun işlenmemesi için elinden gelen bütün gayreti gösteren suç ortağının işlenen suça iştirakten dolayı sorumlu tutulmaması gerekir. Ancak, bu durumda, suç ortağının gönüllü vazgeçme anına kadar gerçekleştirdiği fiillerin bağımsız bir suç oluşturması durumunda, bu suçtan dolayı sorumlu tutulacağı kuşkusuzdur.”

Ancak, bu durumla ilgili olarak uygulamada ciddi bir ispat sorunuyla karşı karşıya gelinebileceğinin bilincinde olmak gerekir.

Fail, azmettiren veya yardım eden statüsündeki diğer suç ortakları ile birlikte işlemeyi kararlaştırdıkları suçun icrasına başlar; ancak pişmanlık duyarak suçun icra hareketlerine devam etmez veya icra hareketlerini bitirmiş olmakla birlikte, neticenin gerçekleşmesini engeller. TCK'nın 36. maddesine göre, gönüllü vazgeçen fail, bu durumda işlemeyi kastettikleri suçtan dolayı cezalandırılmayacaktır. Ancak, failin gönüllü vazgeçme anına kadarki fiillerinin oluşturduğu başka bağımsız suçtan dolayı cezalandırılacağına kuşku yoktur. Yukarıdaki örnekte D'yi öldürmek kastıyla hareket eden B'nin silahından çıkan bir kurşun D'yi yaralar; fakat B, silahında mermi bulunmasına ve atışa devam etmesine engel bir durum mevcut olmamasına rağmen, icra hareketlerine devam etmekten vazgeçer ve hatta, D'nin yarasının iyileşmesi için elinden geleni yapar ve sonuçta D ölmez. İşte bu durumda TCK'nın 36. maddesi hükmü gereğince gönüllü vazgeçen B'yi kasten öldürme suçuna teşebbüsten dolayı cezalandıramayacağız. Ancak, B'nin o ana kadarki fiilleri başka bağımsız bir suç olan kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır ve B'yi ancak bu suç nedeniyle cezalandırmak mümkün olacaktır.

Bu durumda, azmettirmek veya yardım etmek suretiyle bu suçun işlenişine iştirak eden A ve C'nin ne suretle sorumlu tutulacağı hususu, asıl sorunu oluşturmaktadır. Belirtmek gerekir ki, bu durumda A ve C, gönüllü vazgeçmiş değildir ve dolayısıyla, fail B'nin gönüllü vazgeçmiş olmasından azmettiren veya yardım edenin yararlanmasından söz konusu olamaz.

Bu durumda suçun icra hareketlerine başlanmıştır. Dolayısıyla, işlenen suçla ilgili haksızlık kısmen de olsa gerçekleşmiştir. Bu nedenle, gönüllü vazgeçen failin dışındaki diğer suç ortaklarının, işlemeyi kararlaştırdıkları suçtan dolayı teşebbüs hükümlerine göre cezalandırılması gerekecektir.

Gönüllü vazgeçme bakımından tersi bir durumla da karşılaşılabilir. Yukarıdaki örnekte, fail B değil de, azmettiren A veya yardım eden C pişmanlık duyarak suçun icrasından gönüllü vazgeçmek istemiş olabilir.

İşte bu durumla ilgili olarak 41. maddenin ikinci fıkrası hükmünün göz önünde bulundurulması gerekir.

V. Kabahate İştirak

5326 s. Kabahatler Kanununun “İştirak” başlıklı 14. maddesine göre;

“(1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idari para cezası verilir.

(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail olarak idari para cezası verilir.

(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idari para cezası verilir.

(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır.”

Madde gerekçesinde bu hükümlerle ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

*“Maddenin birinci fıkrasında, kabahatlere iştirak haliyle ilgili olarak **tek tip fail sistemi** kabul edilmiştir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişiler arasında fail ve şerik (azmettiren veya yardım eden) ayırımı gözetilmiştir.*

Maddenin ikinci fıkrasında, bağlılık kuralının özgü suçlardaki fonksiyonu kabahatler bakımından kabul edilmemiştir. Özel faillik niteliğini taşıyan kişinin işlediği kabahate bu niteliği taşımayan kişinin iştirak etmesi halinde, bu kişi de fail olarak idari para cezası ile cezalandırılabilir.

Üçüncü fıkra, kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığının gerekli ve yeterli olduğu kabul edilmiştir. Bunun sonucu olarak, kabahatin işlenişine iştirak eden kişilerden birinin, örneğin kusur yeteneğinin olmaması, diğer ortakların idari para cezası ile cezalandırılmasını engellemez.

Herhangi bir kişi açısından kabahat oluşturan fiil, özel faillik niteliğini taşıyan bir başkası açısından suç oluşturabilir. Maddenin dördüncü fıkrası,

bu hallere özgü ve fakat sadece iştirakle ilgili bir hüküm içermektedir. Kişi, kendisi açısından kabahat oluşturan fiili tek başına işlemiş olsaydı, kabahatten dolayı hakkında idari para cezası verilecekti; ancak, özel faillik niteliğini taşıyan bir kişi ile birlikte bu fiili işlemiş olduğu için, artık hakkındaki idari para cezası değil, özel faillik niteliğini taşıyan kişinin işlemiş bulunduğu suça iştirakten dolayı Türk Ceza Kanununun iştirake ilişkin hükümlerine göre hapis veya adli para cezasına hükmolunacaktır.”

§22. Suçların İctimai

I. Kural: Gerçek İctima

Yeni TCK'nın suçların ictimai bakımından benimsediğı kural (**gerçek ictima kuralı**), řu řekilde ifade edilmiřtir:

“Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır”¹²³⁹.

Yeni TCK'da gerçek ictima kuralının ayrıca belirtildiğı çeřitli hükümler yer almaktadır. Bu hükümleri üç temel kategoride toplayabiliriz.

I. Cebrin bir suçun temel veya nitelikli unsurunu oluřturduğı hallerde, ilgili suçun unsurunu oluřturan cebrin ağırlığına iliřkin bir açıklama getirmek gerekir. Yeni TCK'nın benimsediğı sisteme, göre; cebrin unsur olarak kabul edildiğı suçlarda suçun iřleniři sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlařmıř halleri gerçekteřtiğinde, hem ilgili suçtan hem de kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlařmıř halinden (m. 87) dolayı cezaya hükmolunacaktır.

Bu bağlamda, çeřitli suç tanımlarıyla ilgili olarak yeni TCK'dan řu örnekler verilebilir:

a) *Cinsel saldırı suçunun iřlenmesi sırasında uygulanan cebir ve řiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı da cezaya hükmolunur* (m. 102, f. 4; ayrıca bkz. m. 103, f. 5).

b) *Kiřiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun iřlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlařmıř hâllerinin gerçekteřmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmolunur* (m. 109, f. 6).

c) *Eğitim ve öğretilimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlâli ile iř ve çalışma hürriyetinin ihlâli suçlarının iřlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlařmıř hâllerinin gerçekteřmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmolunur* (m. 119, f. 2).

d) *Yağma suçunun iřlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlařmıř hâllerinin gerçekteřmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmolunur* (m. 149, f. 2).

¹²³⁹ TBMM Adalet Komisyonu'nun Türk Ceza Kanunu Tasarısına iliřkin 3.8.2004 tarih ve Esas: 1/593, Karar: 60 sayılı Raporu, TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, řh. 229.

e) *Görevi yaptırmamak için direnme suçunun* işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmolunur (m. 265, f. 5).

II. Bazı suç tanımlarında, suçun unsurlarına ilişkin *kastın yanı sıra*, failin belli bir amaç doğrultusunda hareket etmesi, bir *manevi unsur* olarak aranmaktadır.

Amaç, *kasttan önce gelen, kastı hazırlayan bir düşüncedir*¹²⁴⁰. Kanunî tarifte gerek suçun temel şekli gerek nitelikli şekli açısından bir unsur olarak kabul edilmiş olan amaç, Türk hukuk literatüründe Fransız hukukunun etkisiyle “*özel kast*” olarak ifade edilmiştir¹²⁴¹. Yeni TCK’nın sisteminde, amaç veya saik, *kastla özdeş veya kastın bir türü değildir*. Bu bakımdan, artık “genel kast” – “özel kast” ayırımı terkedilmiştir.

Amaç, bazı suçlar açısından, *suçun temel şekline ilişkin bir unsur* teşkil etmektedir. Örneğin, “*Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt*” kurmak veya yönetmek (m. 220, f. 1; ayrıca bkz. m. 78, f. 1; m. 314, f. 1); göçmen kaçakçılığı suçu açısından, “*maddi menfaat elde etmek maksadı*”nın (m. 79, f. 1) güdülmesi; hırsızlık suçu açısından, “*yarar sağlamak maksadı*”yla hareket edilmesi (m. 141, f. 1); tefecilik suçu açısından, “*kazanç elde etmek amacıyla* başkasına ödünç para” verilmesi (m. 241); rüşvet suçu açısından, bir kamu görevlisinin “*görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için*” kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir menfaat temin etmesi (m. 252, f. 1, 2); görevi yaptırmamak için direnme suçu açısından, “*kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla* cebir veya tehdit” kullanılması (m. 265, f. 1); suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu açısından, “*gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacı*”yla hareket edilmesi (m. 281, f. 1); suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu açısından, bu değerlerin “*gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla*” hareket edilmesi (m. 282, f. 1) hallerinde, amaç ilgili suçun temel şekline ilişkin bir manevi unsuru oluşturmaktadır.

Bazı suçlar bakımından amaç, suçun kanuni tarifinde *suçun nitelikli şekline ilişkin bir unsur* olarak belirtilmiştir. Örneğin, kasten öldürme suçunun, “*bir suç gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla*” (m. 82, bent h); kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun, “*cinsel amaçla*” (m. 109, f. 5); hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarının, “*bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla*” (m. 144, bent b; m. 150, f. 1; m. 159); mala zarar verme suçunun, “*sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla*”

¹²⁴⁰ ARTUK, Halid Kemal Elbir’e Armağan, sh. 66. Ancak, işaret etmek gerekir ki; bizim burada kullandığımız anlamda amaç kavramı karşılığı olarak Türk hukukunda *saik* kavramı kullanılmaktadır (DÖNMEZER/ERMAN II, no. 933, 934; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 311).

¹²⁴¹ ÖNDER, Genel Hükümler II. sh. 312.

la bir kamu görevlisinin zararına olarak” (m. 152, f. 1, bent g); belgede sahtecilik suçunun, “*bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla*” (m. 211) işlenmesi hallerinde, amaç faile daha ağır veya daha az cezaı gerektiren bir nitelikli unsur oluşturmaktadır.

Bazı suçların kanunî tarifinde unsur olarak yer verilen amaç, bir başka fiilin işlenmesine yönelik olabilir. Meselâ rüşvet, bir kamu görevlisinin bir kamu görevlisinin “*görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için*” kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir menfaat temin etmesidir (m. 252, f. 1, 2). Bu suç, haksız menfaatin kamu görevlisi tarafından temin edildiği anda tamamlanmış olur. Ancak, haksız menfaatin temini ile güdülen amaç bilahare gerçekleştirilebilir. Amacı oluşturan fiilin gerçekleşmesi, rüşvet suçunun oluşması açısından gerekli değildir. Keza, bir insanın diğer bir suçu işlemek için öldürülmesi halinde; oluşan kasten öldürme suçunun bu nitelikli şekli açısından, amaçlanan suçun işlenmesi gerekmez. Burada önemli olan, öldürme fiilinin belli bir amaçla işlenmesidir.

Amaçlanan fiilin işlenmesi halinde ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunacaktır. Başka bir deyişle, **amaç suç – araç suç ilişkisinde** amaçlanan suçun ayrıca işlenmesi halinde gerçek içtima kuralları uygulanacaktır.

Bu bakımdan, “*kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt*” kurmak veya yönetmek, Kanunda bağımsız bir suç olarak tanımlanmaktadır (m. 220, f. 1; ayrıca bkz. m. 78, f. 1; m. 314, f. 1). Bu örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, kişi ayrıca bu suçtan dolayı cezalandırılır (m. 220, f. 4).

Keza, kamu görevlisi, *görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için* rüşvet aldıktan sonra, ayrıca örneğin görevinin gereklerine aykırı olarak bir satın alma işini birisine ihale etmişse; hem rüşvet suçundan (m. 252) dolayı, hem de ihaleye fesat karıştırma suçundan (m. 235) dolayı cezalandırılacaktır (m. 235, f. 4).

Bir suçun “*işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla*” kasten öldürme suçu işlendikten sonra, ayrıca bu suç (örneğin hırsızlık) da işlenmiş olabilir. Bu durumda hem kasten öldürme suçunun nitelikli halinden (m. 82, bent h), hem de hırsızlık suçundan (m. 141) dolayı cezaya hükmolunur.

III. Yeni TCK’da başka gerçek içtima hükümlerine de yer verilmiştir. Bu hususta Kanundan şu örnekler verilebilir:

a) *Soykırım suçu veya insanlığa karşı suçlar* kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca cezaya hükmolunur (m. 76, f. 2; m. 77, f. 2).

b) *İşkence suçunun* işlenmesi sırasında mağdura karşı cinsel saldırı suçunun işlenmesi halinde, her iki suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur (m. 94, f. 3 gerekçesi).

c) Tehdit amacıyla, kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, *tehdit suçunun* yanı sıra bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur (m. 106, f. 3).

d) Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem *sahtecilik* hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunacaktır (m. 212)¹²⁴².

e) *Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün* yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır (m. 220, f. 5).

f) *Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunun* işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi veya kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar nedeniyle cezaya hükmolunur (m. 223, f. 4, 5; ayrıca bkz. m. 224, f. 2, 3).

g) *İhaleye fesat karıştırma* dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılır (m. 235, f. 4; ayrıca bkz. m. 236, f. 3).

h) *İftira suçunda*; yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözüaltına alınması veya tutuklanması hâlinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur (m. 267, f. 4; ayrıca bkz. m. 272, f. 5).

i) *Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçunun* işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur (m. 292, f. 4; ayrıca bkz. m. 294, f. 7).

j) *Hükümlü veya tutukluların ayaklanması* sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur (m. 296, f. 2).

k) *Hükümlü ve tutukluların beslenmesinin engellenmesi* nedeniyle kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise, ayrıca kasten yaralama veya kasten öldürme suçlarına ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur (m. 298, f. 3).

l) *Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak ve Anayasayı ihlâl* suçlarının işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde,

¹²⁴² Keza, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 28.3.2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunla değişik 4. maddesinin beşinci fıkrasında “*Bu Kanunda tanımlanan suçların, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.*” hükmüne yer verilmiştir.

ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur (m. 302, f. 2; m. 303, f. 3; m. 309, f. 2; ayrıca bkz. m. 311, f. 2; m. 312, f. 2; m. 313, f. 4).

Ceza kanunlarında gerçek içtima kuralının istisnaları olarak çeşitli hükümlere yer verilmektedir. Yeni TCK’da bu kuralın istisnalarını,

- a) Bileşik suç (m. 42),
 - b) Zincirleme suç (m. 43, f. 1, 3),
 - c) Aynı neviden fikrî içtima (m. 43, f. 2, 3),
 - d) Farklı neviden fikrî içtima (m. 44),
- oluşturmaktadır¹²⁴³.

II. Bileşik Suç

Kanunda bağımsız bir suç olarak tanımlanan fiil, bir başka suçun temel şekline veya daha ağır cezayı gerektiren nitelikli şekline ilişkin unsurunu oluşturabilir. Bu gibi durumlarda bir başka suçun unsurunu oluşturan fiilden dolayı ayrıca

¹²⁴³ Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bir kararında bu prensipler şu şekilde açıklanmıştır:

“TBMM Adalet Komisyonunun TCK tasarısına ilişkin 03.08.2004 gün ve 1/593-60 sayılı raporunda 5237 sayılı TCK’nın içtima bakımından benimsediği kuralın gerçek içtima kuralı olduğu *“kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır”* şeklinde ifade edilmiştir. Ancak yeni Yasada gerçek içtima kuralının istisnalarına da yer verilmiştir: Bileşik suç (m.42), zincirleme suç (m.43/1), aynı neviden fikri içtima (m.43/2-3) ve farklı neviden fikri içtima(m.44)

5237 sayılı TCK’nın 43/2. maddesindeki aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanacağına ilişkin kuralın, aynı maddenin 3. fıkrasındaki, *“(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.”* şeklindeki düzenleme nedeniyle kasten öldürme suçlarında uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Farklı neviden fikri içtima ise 5237 sayılı Yasanın 44. maddesinde; *“(1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır”* biçiminde düzenlenmiştir. Bu kuralın uygulanabilmesi için işlenen bir fiille birden fazla farklı suçun oluşması gerekir. Burada suçun temel ve nitelikli şekilleri de “farklı suç” değil aynı suç olarak değerlendirilmelidir. Tek bir fiille aynı hükmün birden fazla ihlali halinde TCY’nın 44. maddesinin uygulanması söz konusu olmayıp bu gibi hallerde gerçek içtima veya zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşulları düşünülmelidir.”: CGK, **8.7.2008**, E. 2008/1-99, K. 2008/185.

Yeni TCK’nın suçların içtimasına ilişkin düzenlemeleri ve bu bağlamda **gerçek içtima**, **zincirleme suç**, **aynı neviden fikri içtima** ve **farklı neviden fikri içtima** müesseseleri hakkında genel bilgilerin yer aldığı kararlar için bkz. CGK, **26.6.2012**, E. 2011/15-420, K. 2012/249; CGK, **20.3.2012**, E. 2011/2-433, K. 2012/108; CGK, **28.2.2012**, E. 2010/2-287, K. 2012/58; CGK, **29.6.2010**, E. 2010/8-51, K. 2010/162; CGK, **30.3.2010**, E. 2010/11-17, K. 2010/65; CGK, **8.12.2009**, E. 2009/9-153, K. 2009/285.

Suçların içtiması ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. GÖKTÜRK, Neslihan: *Fikri İçtima (Suçların İçtiması)*, Ankara, 2013; DEMİRTAS, Soner: *Die Konkurrenzlehre im deutschen und türkischen Strafrecht*, Berlin, 2016.

cezaya hükmolunmaz. Örneğin, tehdit veya cebir kullanmak suretiyle yağma suçunun (m. 148) işlenmesi halinde, kişiye yağma suçunun yanı sıra ayrıca tehdit (m. 106) veya kasten yaralama (m. 86) suçundan dolayı ceza verilmez.

Bu hususa açıklık getirmek amacıyla 765 s. TCK'da (m. 78) olduğu gibi, yeni TCK'da da bir hükme yer verilmiştir:

“Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.” (m. 42).

Düşüncemize göre, **bileşik** (mürekkep) suça ilişkin olarak Kanunun genel hükümleri kapsamında bir düzenleme yapılması gereksizdir. Yeni TCK'ya ilişkin TBMM Adalet Komisyonundaki çalışmalarımız sırasında bu düşüncemizi dile getirmemize rağmen, Hükümet Tasarısındaki hüküm (m. 54) gerekçesi ile birlikte aynen muhafaza edilmiştir. Aslında yeni TCK'ya ilişkin TBMM Adalet Komisyonundaki çalışmalarda esas alınan suç teorisinde “ağırlaştırıcı neden” veya “hafifletici neden” kavramları kullanılmadığı halde, Hükümet Tasarısından aynen iktibas edilen bu hükümde “unsur” ve “ağırlaştırıcı neden” ayırımına yer verilmiştir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, TBMM Adalet Alt Komisyonunda yeni TCK Tasarısına ilişkin çalışmalar sırasında, 765 s. (mülga) TCK'da bileşik (mürekkep) suça örnek olarak gösterilen hallerin bir kısmında her bir fiilin ayrı ayrı suç oluşturması yönünde girişimimiz olmuştur.

Düşüncemize göre, örneğin, hırsızlık suçunun işlenişi sırasında ayrıca başkasının malına zarar verilmiş ise, hırsızlık ve mala zarar verme olmak üzere iki ayrı suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir¹²⁴⁴. Keza, hırsızlık suçunu işlemek amacıyla baş-

¹²⁴⁴ Buna göre, hırsızlık suçunun işlenmesi sırasında, hırsızlık konusunu oluşturan malın dışında başka eşyaya zarar verilmesi halinde, örneğin hırsızlığın yapılacağı eve veya iş yerine girebilmek için kapının kırılması halinde, ayrıca mala zarar verme suçu (TCK, m. 151, 152) oluşur.

Ancak, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan eşyaya zarar verilmesi halinde, kişiyi sadece tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış hırsızlık suçundan dolayı cezalandırabiliriz. Bu durumda ayrıca mala zarar verme suçundan dolayı kişiye ceza verilmez. Hırsızlık konusu malın örneğin bulunduğu yerden sökülüp alınabilmesi için kendisine zarar verilmesi, bilahare yenilip tüketilmesi veya beklentiye cevap verecek değerde olmaması sebebiyle kırılıp atılması hallerinde, fail hırsızlık suçundan dolayı cezalandırılacağı için, ayrıca hırsızlık konusu mala zarar vermek dolayısıyla cezalandırılmaz. Ancak, bu durumda fiilin suç oluşturmaması sebebiyle değil, olayda hırsızlık suçunu işleyen fail bakımından bir **şahsi cezasızlık sebebinin** bulunması dolayısıyla, faile ceza verilmemektedir.

Yargıtay **Ceza Genel Kurulu** da çeşitli kararlarında, gerekçesine iştirak etmemekle birlikte aynı sonuca varmıştır:

“Hırsızlık ve mala zarar verme suçları 5237 sayılı TCK'nın onuncu bölümünde “Mal varlığına karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olup her iki suçun da koruduğu hukuki değer kişinin mal varlığıdır. Hırsızlık eyleminde zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malın, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden tamamının

kasının konutuna girilmiş olması halinde hırsızlık suçunun yanı sıra ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekecektir.

Yeni TCK Tasarısına ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporunda da vurgulandığı üzere, “*Hükûmet Tasarısına 765 sayılı Türk Ceza Kanunundan yansıyan örneğin hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili kazüistik mahiyetteki bazı hükümler sadeleştirilmeye çalışılmıştır.*”¹²⁴⁵.

765 s. Kanunda hırsızlığın “... duvar, kapı, pencere, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi şahısları veya malları muhafaza için sağlam maddelerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yıkmak, devirmek, kırmak, delmek veya mahvetmek ... suretiyle” işlenmesi halinde, faile daha ağır ceza verilmesi öngörülmüştü (m. 493, f. 1, bent 1). Yeni TCK’nın sisteminde ise, hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla veya sırasında başkasının malvarlığına zarar verilmiş olması halinde; malvarlığına zarar vermek fiili, hırsızlık suçunun yanında bu suçtan ayrı ve bağımsız suç olma özelliğini muhafaza etmektedir. Başka bir deyişle bu durumda, 765 s. Kanunun sisteminde olduğu gibi artık bir mürekkep (bileşik) suç söz konusu değildir; fail hakkında hem hırsızlık (m. 141 vd.) hem de mala zarar vermek (m. 151 vd.) suçundan dolayı cezaya hükmolunacaktır¹²⁴⁶.

765 s. TCK’da hırsızlığın bina içinde gerçekleştirilmesi (“bina içinde hırsızlık”: m. 491, f. 3, bent 4; m. 492, f. 1, bent 1), bu suçun “ağırlatıcı sebebi” olarak kabul edilmekteydi. Başka bir deyişle, hırsızlık suçunun konuta girmek suretiyle

veya bir kısmının alınması suretiyle müştekinin malvarlığına zarar verilirken, mala zarar verme suçunda ise; başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkip, tahrip edip ya da yok etmek suretiyle kullanılamaz hâle getirerek veya kirleterek zarar verilmesi söz konusudur. Her iki suç tipinde de mağdur malvarlığı itibarıyla zarar görmektedir. Hırsızlık suçunda, suçta konu mal alınıp götürülmek suretiyle mağdurun zilyetliği tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Mala zarar verme suçunda ise, malın mutlaka alınması gerekli olmayıp, çoğunlukla malın tamamı ortadan kaldırılmamakta, zarar verilerek kısmen veya tamamen kullanılamaz hale getirilmektedir. İki suç bir birinden ayıran önemli özellik ise; hırsızlıkta failin faydalanma amacıyla eylemini gerçekleştirmesine karşın, mala zarar verme suçunda mağdura zarar verme düşüncesiyle hareket etmesidir. Bu nedenle **mala zarar verme suçunun konusu ile hırsızlık suçunun konusunun aynı tanıştır mal olması halinde, ayrıca mala zarar verme suçundan da ceza verilmemesi gerekmektedir. Ancak hırsızlık eylemi gerçekleştirilirken suçta konu mal dışında bir başka eşyaya zarar verilmiş ise, mala zarar verme suçu ayrıca gerçekleştirilebilir.** Örneğin, aracın camı kırılarak içerideki telefonun alınması halinde hırsızlık suçu yanında, ayrıca hırsızlık suçunun konusunu oluşturmayan araç camının kırılmış olması nedeniyle mala zarar verme suçu da oluşacaktır. Bununla birlikte, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan eşyanın çalınması sırasında ayrıca bu eşyaya zarar verilmesinin de söz konusu olduğu hallerde, bu durum 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulmalıdır.”: CGK, 30.10.2014, E. 2014/2-40, 2014/453; CGK, 14.10.2014, E. 2013/2-560, K. 2014/416; CGK, 6.5.2014, E. 2013/2-687, K. 2014/228; CGK, 8.4.2014, E. 2013/2-683, K. 2014/174.

¹²⁴⁵ TBMM Adalet Komisyonu’nun Türk Ceza Kanunu Tasarısına ilişkin 3.8.2004 tarih ve Esas: 1/593, Karar: 60 sayılı Raporu, TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 235.

¹²⁴⁶ Aynı doğrultuda görüş için bkz. PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer: *Türk Ceza Kanunu Yorumu*, cilt 2, Ankara, Şubat 2007, sh. 1065.

işlenmesi halinde, 765 s. Kanunun sisteminde kişi hakkında sadece hırsızlık suçundan dolayı cezaya hükmedilmekte idi; kişiye konut dokunulmazlığını ihlalden dolayı ayrıca ceza verilmemekte idi. Yeni TCK'ya ilişkin TBMM Adalet Alt Komisyonunda yapılan çalışmalarda hırsızlık suçunun konusunun muhafaza altına alınmış eşya olması bu suçtan dolayı daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak kabul edilmesinin yeterli olduğu yönünde bulunduğumuz öneri başta uygun görüldüyse de, bilahare madde metnine (yeni TCK, m. 142, f. 1, bent b)¹²⁴⁷ yapılan ilavelerle, 765 s. Kanunun sistemine yaklaşılmıştır¹²⁴⁸. Buna göre, “*Hırsızlık suçunun ... herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, ... işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.*” Bu düzenlemeden, “*hırsızlık suçunun ... bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, ... işlenmesi hâlinde,*” failin sadece bu suçun söz konusu nitelikli halinden (m. 142, f. 2, bent h) dolayı cezalandırılacağı; ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali suçundan dolayı cezaya hükmolunmayacağı sonucu çıkarılabilir.

Ancak, belirtmek gerekir ki, Yargıtay, yeni TCK'nın bu düzenlemesi karşısında, konuta girilmek suretiyle işlenen hırsızlık suçlarında hem konut dokunulmazlığının ihlali suçunun hem de hırsızlık suçunun oluştuğu ve her iki suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur¹²⁴⁹.

¹²⁴⁷ Bu bent hükmü, bilahare maddede 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle maddenin ikinci fıkrasına h bendi olarak taşınmıştır.

¹²⁴⁸ Aynı durum, yağma ve dolandırıcılık suçları bakımından da söz konusudur.

¹²⁴⁹ TCK'nın 142. maddesinin birinci fıkrasındaki “*Hırsızlık suçunun;...b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,... İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur*” şeklindeki düzenleme ile, “yasa koyucu ... hırsızlık suçunun “*bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya*” hakkında işlenmiş olması halini (bu suç bakımından) nitelikli bir hal olarak düzenlemiş, bina veya eklentiye girmeyi bu suçun oluşumu açısından bir unsur olarak aramamıştır. Buna göre hırsızlık suçunun bu nitelikli halinin, “*bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya*” hakkında bina veya eklentileri içine girilerek işlenmesi olanaklı olduğu gibi bina veya eklentiye girilmeden de işlenebilmesi olanaklı olup her iki durumda da Yasanın 142/1-b maddesinin uygulanması gerekecektir. Başka bir anlatımla; maddedeki düzenleme ile, bina veya eklentilerine girilip girilmemesi hususu değil, çalınan eşyanın bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olması nitelikli hal açısından önemsenmiştir. Yasa koyucu, bu suç tipini bileşik suç olarak düzenlemek isteseydi, madde metnini “*bina veya eklentilerine girmek suretiyle işlenirse*” şeklinde düzenlerdi. Bu nedenle, hırsızlık suçunun bu nitelikli halinin işlenmesi sırasında bina veya işyerine girilmiş olması halinde hırsızlık suçunun yanında ayrıca konut dokunulmazlığını bozma suçu da oluşmakta ve buna bağlı olarak failin bu suçtan da cezalandırılması gerekmektedir.

Bunun yanında, yasa koyucu bu iradesini pekiştirecek şekilde 5560 sayılı Yasanın 6. maddesiyle 5237 sayılı TCY'nın 142. maddesine; “*Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz*” şeklindeki 4. fıkrayı eklemiştir. Eklenen fıkranın gerekçesinde de; “*Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ce-*

Bu içtihat karşısında ve gereksiz tartışmayı önlemek için, TCK'nın 142. maddesine 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla dördüncü fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir:

“Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.”

Bu fıkranın **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir:

“‘Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza’ kuralı gereğince, hırsızlık suçunu işlemek için başkasının konutuna girilmesi veya malvarlığına zarar verilmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmetmek gerekir. Ancak, her iki suçun temel şekli, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suç olduğu için; örneğin konut dokunulmazlığını işlemek suretiyle hırsızlık suçunun işlenmesi halinde, konut dokunulmazlığının temel şekli uzlaşma kapsamına girmekte ve fakat, hırsızlık suçu uzlaşma kapsamı dışında kalmakta ve bu durumlarda, uygulamada, hırsızlık suçundan dolayı soruşturmanın bekletilmesi veya ayrı yürütülmesi gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Belirtilen sakıncanın ortadan kaldırılması amacıyla 5237 sayılı Kanunun 142'nci maddesine (söz konusu dördüncü fıkra) eklenmiştir.”^{1250,1251}

za’ kuralı gereğince, hırsızlık suçunu işlemek için başkasının konutuna girilmesi veya malvarlığına zarar verilmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmetmek gerekir” denilmek suretiyle yasa koyucunun amacının, hırsızlık suçunun işlenmesi sırasında işlenen diğer suçların da ayrıca cezalandırılması olduğu açıkça ortaya konulmaktadır.

Bu nedenle 5237 sayılı TCY'nın 142/1-b maddesinde düzenlenen suç bileşik suç niteliğinde olmadığından hırsızlık suçunun işlenmesi sırasında konut dokunulmazlığını ihlal suçunun da işlenmesi halinde, failin ayrıca bu suçtan da cezalandırılması gerekmektedir.” CGK, **8.12.2009**, E. 2009/9-153, K. 2009/285. Ayrıca bkz.CGK, **19.6.2012**, E. 2011/6-483, K. 2012/240; CGK, **9.10.2012**, E. 2012/6-375, K. 2012/1809.

¹²⁵⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1255, sh. 18 vd.

¹²⁵¹ 142. maddeye dördüncü fıkra olarak eklenen bu hüküm, uzlaşma müessesesinin işleyişi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Hırsızlık suçu uzlaşma kapsamına girmemektedir. Hırsızlık suçunun işlenişi sırasında kişinin malvarlığına örneğin kapıyı veya pencereyi kırmak suretiyle zarar verilmesi halinde, şikâyete bağlı bir suç olduğu için mala zarar verme suçundan dolayı uzlaştırma yoluna gidilmesi gerekecekti. Keza, ister gece ister gündüz işlenmiş olsun, konut dokunulmazlığının ihlali suçu uzlaşma kapsamına girmektedir (CMK, m. 253, f. 1, bent b, alt bent 3). Hırsızlık amacıyla konuta girilmesi durumunda, bu düzenleme nedeniyle konut dokunulmazlığının ihlali suçu dolayısıyla uzlaştırma yoluna gitmek gerekecekti. Söz konusu dördüncü fıkra 142. maddeye eklenirken, mala zarar verme veya konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından dolayı hırsızlık suçunun mağduruna şikâyetçi olup olmadığının sorulması ve uzlaşma teklifinde bulunulması karşısında gösterilebilecek olan refleks göz önünde bulundurulmuştur.

Ancak, bu düzenleme uygulamada başka bir tartışmaya neden olmuştur. Örneğin cinsel saldırı suçunun işlenmesi amacıyla mağdurun konutuna girilmiş olması halinde, konut dokunulmazlığının ihlali suçu ile ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilip gidilemeyeceği tartışma konusu

Ancak, yeni TCK'nın hazırlanışı sırasında “*Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza*” kuralını benimseme hususundaki gayretlerimizde yeterince başarılı olduğumuz söylenemez. Yeni TCK'nın yağma suçunun nitelikli halinin düzenlendiği 149. maddesine göre, bu suçun “*konut veya işyerinde ... işlenmesi hâlinde,*” failin daha ağır ceza ile cezalandırılması gerekecektir (bent d). Bu düzenleme karşısında da, “*yağma suçunun ... konut veya işyerinde ... işlenmesi hâlinde,*” fail sadece yağma suçunun bu nitelikli halinden dolayı cezalandırılacaktır; ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali suçundan dolayı cezaya hükmolunmayacaktır¹²⁵².

III. Zincirleme Suç

Zincirleme suç hâlinde, **aynı suçun birden fazla** işlenmiş olması söz konusudur. Ancak, bu suçlar, **bir suç işleme kararının** icrası kapsamında işlenmektedir, yani bu suçlar arasında **sübjektif bir bağ** bulunmaktadır.

Zincirleme suçun söz konusu olabilmesi için aranan ilk şart, **birden çok fiilin** bulunmasıdır. Ancak, işlenen fiillerden her birinin **aynı suç** oluşturması gerekir. “*Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.*” TCK, m. 43, f. 1, ikinci cümle)¹²⁵³.

yapılmıştır. Mağdurun konutuna girildikten sonra cinsel saldırı suçunun işlenmesi halinde iki ayrı suç söz konusudur. Bunlardan birincisi konut dokunulmazlığının ihlali, diğeri ise cinsel saldırı suçudur. Bu iki suçtan dolayı fail hakkında gerçek içtima hükümlerine göre cezaya hükmolunur. Cinsel saldırı suçunun mağduruna, konut dokunulmazlığını ihlal ettiği için ayrıca bu suçtan dolayı da cezalandırılabilmesi için fail hakkında şikâyetçi olup olmadığının sorulmasının makul karşılanmayacağı malumdur.

Bu gibi durumlarda karşılaşılan şikâyet sorununun içtihatla çözümlenebileceği kanısındayız. Şayet bu hususa özgü bir kanun hükmüne ihtiyaç duyulacaksa, TCK'nın 73. maddesinin 5560 s. Kanunla yürürlükten kaldırılan sekizinci fıkrasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi yoluna gidilebilir:

“Şikâyeteye bağlı bir suçun, re’sen soruşturulabilen başka bir suçun işlenmesi amacıyla işlenmesi halinde, bu suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.”

¹²⁵² Mağdurun konutuna girilerek yağma suçunun işlenmesi halinde, aslında konut dokunulmazlığının ihlali ve yağma olmak üzere iki ayrı suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Ancak, konut dokunulmazlığının ihlali suçu yağma suçunun bir nitelikli unsurunu oluşturduğu için, bu gibi durumlarda artık sadece yağma suçunun nitelikli halinden dolayı cezaya hükmetmek gerekir; ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali suçundan dolayı cezaya hükmedilemez (yeni TCK, m. 42).

Söz konusu bent hükmü bu mantık çerçevesinde bir yorumlamaya tabi tutulduğunda, bu nitelikli unsurun ancak **mağdurun konut veya işyerinde yağma suçunun işlenmesi halinde** oluşacağını kabul etmek mümkün olacaktır.

¹²⁵³ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 5.6.2012 tarihli ve E. 2011/15-491, K. 2012/219 sayılı Kararında, **resmi belgede sahtecilik** suçu ile **özel belgede sahtecilik** suçu, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bağlamında “*aynı suç*” olarak kabul edilmiştir. Her iki suçun da “benzer bir şekilde düzenlenmiş” olduğu gerekçesiyle varılan bu sonucun, gerekçesi de dahil olmak üzere doğru olmadığı izahtan varestedir. Ne resmi belgede sahtecilik suçu özel belgede sahtecilik suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli şeklini, ne de özel belgede sahtecilik

Zincirleme suç halinde, ortada bir suç değil, **birden fazla suç** mevcuttur¹²⁵⁴.

Zincirleme suçtan söz edebilmek için, aynı suçun müteaddit defa **aynı kişiye karşı** işlenmesi gerekir. İşlenen suçların mağdurunun **aynı kişi** olması gerekir. Her gün aynı kişiye hakaret edilmesi (m. 125) veya cinsel tacizde bulunulması (m. 105) gibi durumlarda, aslında hakaret ve cinsel taciz gibi suçlar birden fazla işlenmektedir. Ancak, bu suçlar arasındaki **manevi bağ** dolayısıyla, zincirleme suçun varlığı kabul edilmektedir. Keza, bir kişiye karşı müteaddit defa hırsızlık suçunun işlenmesi halinde de, zincirleme suç söz konusudur.

Suçun mağdurunun farklı kişiler olması halinde, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Buna karşılık, 765 sayılı Kanunun sisteminde ise (m. 80), farklı kişilere karşı işlenen suçlar açısından da zincirleme suç hükümleri uygulanabilmekteydi. Yeni Türk Ceza Kanununun bu düzenlemesi karşısında zincirleme suçun uygulama alanı 765 sayılı Kanuna nazaran oldukça daraltılmıştır^{1255, 1256}.

suçu resmi belgede sahtecilik suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli şeklini oluşturur. Her iki suç, Kanunda birbirinden bağımsız olarak düzenlenmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçu **seçimlik hareketli** bir suç iken, özel belgede sahtecilik suçu **çok hareketli** bir suçtur. Bu itibarla, her iki suçun “benzer şekilde düzenlenmiş” olduğu yönündeki kabulün bilimsel ve hukuki bir temeli bulunmamaktadır.

¹²⁵⁴ Oysa Yargıtay Ceza Genel Kurulunun yeni bir kararında, zincirleme suç halinde “*birden fazla neticenin meydana gelmesi*”nden söz edilmiş ve “*tek suçun oluşacağı*” kabul edilmiştir: CGK, **18.12.2012**, E. 2012/11-999, K. 2012/1862.

¹²⁵⁵ “5237 sayılı TCK’na hakim olan ilke gerçek içtima olduğundan, bunun sonucu olarak, “*kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza*” söz konusu olacaktır. Nitekim bu husus Adalet Komisyonu raporunda da; “*Ceza hukukunun temel kurallarından birisi, ‘kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır’ şeklinde ifade edilmektedir. Bunun istisnaları, suçların içtimaı bölümünde belirlenmiştir. Bu istisnalar dışında, işlenen her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir. Böylece verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır*” şeklinde ifade edilmiştir. Bu kuralın istisnalarına ise, 5237 sayılı TCK’nın “suçların içtimaı” bölümünde, 42 (bileşik suç), 43 (zincirleme suç) ve 44. (fikri içtima) maddelerinde yer verilmiştir.

Konumuza ilişkin olan zincirleme suç, 765 sayılı Kanunun 80. maddesinde; “*Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün bir kaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır. Fakat bundan dolayı terettüp edecek ceza altıda birden yarıya kadar artırılır*” şeklinde düzenlenmiştir. Buna karşın 5237 sayılı Kanunun 43. maddesinin ilk fıkrasında; “*Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır*” biçiminde zincirleme suç düzenlemesine yer verilmiş, ikinci fıkrasında; “*Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır*” denilmek suretiyle aynı neviden fikri içtima kurumu hüküm altına alınmış, üçüncü fıkrasında ise; “*Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, ... ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz*” düzenlemesi ile zincirleme suç ve aynı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanamayacağı suçlar belirtilmiştir.

TCK’nın 43/1. maddesi düzenlemesinden anlaşılabileceği üzere, zincirleme suç hükümlerinin uygulandığı hallerde aslında işlenmiş birden fazla suç olmasına karşın, fail bu suçların her birin-

den ayrı ayrı cezalandırılmamakta, buna karşın bir suçtan verilen ceza belirli bir miktarda artırılmaktadır.

5237 sayılı TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için;

- a- Aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi,
- b- İşlenen suçların mağdurlarının aynı kişi olması,
- c- Bu suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmesi gerekmektedir.

Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan unsurların üzerinde ayrıtılı olarak durulmasında yarar bulunmaktadır.

- a) Aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi;

Aynı suç 5237 sayılı TCK'nın 43. maddesinde; *“Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır”* demek suretiyle açıklığa kavuşturulmuştur. Öğretide de *“aynı suçtan anlaşılması gerekenin, aynı suç tipi olduğu”*, kanunda düzenlenen suçların ismi aynı ise aynı suçtan söz edileceği, suçun ismi farklı ise artık aynı suçtan bahsedilemeyeceği kabul edilmektedir. Buna göre suçların ismi aynı ise aynı suçtan söz etmek mümkün iken, suçun ismi değiştiğinde artık aynı suçtan bahsetmek mümkün değildir. Örneğin dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık eylemleri aynı suç sayılır iken, dolandırıcılık ile güveni kötüye kullanma, hırsızlık ile dolandırıcılık, hırsızlık ile suç eşyasını satın alma aynı suç kavramı içerisinde değerlendirilemeyecektir. Aynı suç kavramına, suçun teşebbüs aşamasında kalmış hali de dahildir. Zincirleme suç oluşturan eylemlerden bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, işlenen suçların isimleri değişmediği sürece, aynı suç sayılacaktır.

765 sayılı TCK'nda yer alan *“muhtelif zamanlarda vaki olsa bile”* ifadesi karşısında, aynı suç işleme kararı altında birden fazla suçun aynı zamanda işlenmesi durumunda diğer şartların da varlığı halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi mümkündür. Nitekim, 765 sayılı TCK'nın yürürlüğü zamanında bu husus yargısal kararlarla kabul edilmiş ve uygulama bu doğrultuda yerleşmiştir.

5237 sayılı TCK'nın 43/1. maddesinde bulunan *“değişik zamanlarda”* ifadesinin açıklığı karşısında, zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için suçların farklı zamanlarda işlenmesi gerektiği konusunda öğreti ve uygulamada tam bir görüş birliği bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, **aynı mağdura, aynı zamanda, aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda tek suçun oluşacağı** kabul edilmiştir. Bu halde zincirleme suç hükümleri uygulanarak artırım yapılamayacak, ancak bu husus TCK'nın 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesinde gözönünde bulundurulacaktır.

- b) İşlenen suçların mağdurlarının aynı kişi olması;

Mağdur; Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde, *“haksızlığa uğramış kişi”* olarak tanımlanmaktadır. Ceza hukukunda ise mağdur kavramı, suçun konusunun ait olduğu kişi ya da kişilerdir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun hazırlanmasında esas alınan suç teorisinde suçun maddi unsurları arasında yer alan mağdur, ancak gerçek bir kişi olabilecek, tüzel kişilerin suçtan zarar görmeleri mümkün ise de bunlar mağdur olamayacaklardır. Suçtan zarar gören ile mağdur kavramları da aynı şeyi ifade etmemektedir. Mağdur suçun işlenmesiyle her zaman zarar görmekte ise de, suçtan zarar gören kişi her zaman suçun mağduru olmayabilir. Bazı suçlarda mağdur belirli bir kişi olmayıp; toplumu oluşturan herkes (geniş anlamda mağdur) olabilecektir. c) Bu suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmesi;

Ceza Genel Kurulunun (çeşitli) kararlarında *“aynı suç işleme kararı”* kavramından, kanunun aynı hükmünü birçok kez ihlal etme hususunda önceden kurulan bir plan, genel bir niyetin anlaşılması gerektiği, bu bağlamda failin suçu işlemekten önce bir plan yapmasının veya bu suça niyet etmesinin, fakat fiili bir defada yapmak yerine, kısımlara bölmeyi ve o surette gerçekleştirmeyi daha uygun görmesinin, hareketinin önceki hareketinin devamı olmasının ve tüm ha-

reketleri arasında subjektif bir bağlantı bulunmasının anlaşılması gerektiği kabul edilmiş, ilk eylemle ikinci eylem arasında makul sayılamayacak uzunca bir sürenin geçmesinin, sanığın aynı suç işleme kararıyla değil, çıkan fırsatlardan yararlanmak suretiyle suçu işlediğini gösterdiği belirtilmiştir.

...

Suç kastından daha geniş bir anlamı içeren suç işleme kararı, suç kastından daha önce gelen genel bir karar ve niyeti ifade etmektedir. Önce suç işleme kararı verilmekte ve bundan sonra bu genel kararın icrası farklı zamanlardaki suçlarla gerçekleştirilmektedir. Kararın gerçekleştirilmesi için gerekli suçların her birinde ayrı suç kastları, bir başka deyişle bir suç için gerekli olan maddi ve manevi unsurlar ayrı ayrı yer almaktadır. Böylece suç işleme kararı denilen genel plân, niyet veya karar, zinciri oluşturan ve her biri birbirinden bağımsız olan suçları birbirine bağlayan ortak bir zemini oluşturur.

Suç işleme kararının yenilenip yenilenmediği, birden çok suçun aynı karara dayanıp dayanmadığı, aynı zamanda suçlar arasındaki süre ile de ilgilidir. İşlenen suçların arasında kısa zaman aralıklarının olması suç işleme kararında birlik olduğuna; uzun zaman aralıklarının olması ise suç işleme kararında birlik olmadığına karine teşkil edebilecektir. Yine de çeşitli suçlar arasında az veya çok uzun zaman aralığının var olması, bu suçların aynı suç işleme kararının etkisi altında işlendiğini ya da işlenmediğini her zaman göstermeyecektir. Diğer bir anlatımla, sürenin uzunluğu kararın yenilendiğini düşündürebileceği gibi, kısalığı da her zaman kararın yürürlükte olduğunu göstermeyebilecektir. Diğer taraftan, hukuki veya fiili kesintiler olduğunda farklı değerlendirmeler yapılması mümkündür. Ancak bu değerlendirme her olayda ayrı ayrı ve diğer şartlar da dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu nedenle, başlangıçta belirli bir süre geçince suç işleme kararı yenilenmiş ya da değişmiş olur demek, soyut ve delillerden kopuk bir değerlendirme olacaktır. Failin iç dünyasını ilgilendiren bu kararın varlığının her olayın özelliğine göre suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işlendikleri yer ve işlenme zamanı, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluşum ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler değerlendirilerek belirlenmesi gerekecektir.

Görüldüğü üzere, zincirleme suçun oluşumu için işlenen suçlar arasında ne kadar zaman geçmesi gerektiği konusunda genel ve mutlak bir kural koymak mümkün olmadığından, hangi süre içerisinde işlenirse işlensin, işlenen suç başlangıçtaki genel niyete veya suç işleme konusundaki tek karara dayanıyor ise zincirleme suç hükümleri uygulanacak, ancak işlenen suç failin yeni bir suç işleme kararına dayanıyorsa artık zincirleme suç söz konusu olmayacaktır.

Zincirleme suça ilişkin bu genel açıklamalardan sonra uyuşmazlığın çözümüne katkısı bakımından "hukuki kesinti" kavramı üzerinde durulması gerekmektedir.

Yapılmakta olan soruşturma sonucunda toplanan delillerin failin suçu işlediği yönünde yeterli şüphe oluşturması üzerine Cumhuriyet savcısınca şüpheli hakkında CMK'nın 170. maddesi uyarınca iddianamenin düzenlenmesiyle hukuki kesinti oluşmaktadır. İddianamenin düzenlenmesiyle olaylar arasında hukuki kesinti olduğundan iddianamenin düzenlenmesinden sonra devam eden eylemler ise başka bir ceza soruşturmasının konusunu oluşturacaktır. Başka bir anlatımla sanık hakkında iddianame düzenlendikten sonra, sanık tarafından aynı suçun tekrar işlenmesi durumunda, yeni ve ayrı bir suç söz konusu olacaktır.

Buna karşın işlenmiş olduğu suçtan dolayı henüz hakkında iddianame düzenlenmeden, sanığın aynı suç işleme kararıyla ve aynı mağdura karşı yeniden suç işlemesi durumunda, hukuki kesinti gerçekleşmeden aynı suçun işlenmesi söz konusu olduğundan sanık hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Bu ahvalde sanığın her suçtan ayrı ayrı cezalandırılması yoluna gidilmeyecek, sanığa bir suçtan ceza verildikten sonra hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle cezasından artırım yapılacaktır.

Buna göre, soruşturma aşamasında sanığın aynı suç işleme kararıyla, aynı mağdura karşı değişik zamanlarda aynı suçu işlediğinin tespit edilmesi durumunda, soruşturma dosyalarının bir-

leştirilerek kamu davası açılması, bu hususa riayet edilmeden kamu davalarının açılması halinde ise hukuki kesintinin oluşmasından önce sanığın aynı mağdura karşı bir suç işleme kararıyla aynı suçu değişik zamanlarda işlediğinin anlaşılması durumunda dava dosyalarının birleştirilerek sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına değerlendirilmesi isabetli bir uygulama olacaktır.

Nitekim Ceza Genel Kurulu 18.09.2012 gün ve 1244-1775 ile 12.03.1996 gün ve 24-34 sayılı kararlarında; "*mahkumiyet hükmü, şikayetten vazgeçme üzerine verilen düşme kararı ve affı yarasında olduğu gibi iddianamenin düzenlenmesi de hukuki kesinti oluşturmaktadır. Mütemadi suçlarda hukuki kesintiden sonra fiile devam edilmesi, müteselsil suçlarda ise fiilin tekrarlanması yeni ve müstakil bir suçu oluşturmaktadır*", 11.03.2003 gün ve 325-28 sayılı kararında; "*iddianame düzenlenmesiyle hukuki kesinti husule geldikten sonraki zapt ve tasarruf eylemleri ayrı bir suçu oluşturur*", 05.02.2002 gün ve 28-179 sayılı kararında; "*iddianameyle dava açılması gibi suçta hukuki kesinti husule gelmesi halinde ayrı bağımsız suçlar oluşur*", 03.02.1998 gün ve 306-2 sayılı kararında; "*iddianamenin düzenlenmesi suçta hukuki kesinti meydana getirir. Mütemadi suçlarda hukuki kesintiden sonra eyleme devam edilmesi yeni ve müstakil bir suçu oluşturduğundan bu konuda ayrıca bir dava açılması zorunludur*" sonucuna ulaşmıştır.

... 1412 sayılı CMUK'da iddianamenin kabulü kurumuna yer verilmemesi nedeniyle Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen iddianamenin mahkemeye verilmesiyle kamu davasının açıldığının kabul edildiği, ancak 5271 sayılı CMK'nın 175. maddesinde iddianamenin kabulü kurumuna yer verilmesi nedeniyle kamu davasının açılmasının iddianamenin kabulü koşuluna bağlandığı görülmektedir. Diğer bir anlatımla kovuşturmanın başlaması için düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi şarttır. Bu nedenle 01.06.2005 tarihinden sonra düzenlenen iddianamelerin hukuki kesinti oluşturabilmesi için mahkemece kabul edilmiş olması gerekir.

Buna göre mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin düzenlendiği tarihten itibaren hukuki kesinti oluşacak, sonra devam eden eylemler başka bir ceza davasının konusunu oluşturacaktır. Başka bir anlatımla sanık hakkında mahkemece kabul edilmek şartıyla **iddianame düzenlendikten sonra**, sanık tarafından aynı suçun tekrar işlenmesi durumunda hukuki kesinti nedeniyle yeni ve ayrı bir suç söz konusu olacak, mahkeme tarafından iddianame iade edildiği aşamada ise aynı suç işleme kararıyla ve aynı mağdura karşı yeniden suç işlemesi durumunda hukuki kesinti gerçekleşmediğinden sanık hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Aynı mağdura ait işyerinden 10.05.2009 ve 24.05.2009 tarihlerinde hırsızlık yapan sanık hakkında ilk olayla ilgili 13.05.2009 tarihinde iddianame düzenlendiği, bu iddianamenin de 26.05.2009 tarihinde mahkemece kabulüne karar verildiği olayda; 13.05.2009 tarihli iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi nedeniyle bu **iddianamenin düzenlenme tarihi itibarıyla hukuki kesinti oluştuğundan** 24.05.2009 tarihinde gerçekleştirilen ikinci eylemin ayrı bir suç olarak değerlendirilerek iki ayrı hırsızlık suçundan hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.”: CGK, **17.3.2015**, E. 2014/2-37, K. 2015/47. Ayrıca bkz: CGK, **16.5.2017**, E. 2015/7-593, K. 2017/273; CGK, **16.5.2017**, E. 2015/7-398, K. 2017/272; CGK, **12.4.2016**, E. 2014/8-690, K. 2016/188; CGK, **15.3.2016**, E. 2014/10-847, K. 2016/128; CGK, **20.5.2014**, E. 2013/7-465, K. 2014/276; CGK, **8.4.2014**, E. 2013/7-591, K. 2014/171.

Zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına ilişkin kararlar için ayrıca bkz: **CGK, 23.9.2014**, E. 2014/10-453, K. 2014/387; **14.1.2014**, E. 2013/14-384, K. 2014/2.

¹²⁵⁶ “Yapılmakta olan soruşturma sonucunda toplanan delillerin failin suçu işlediği yönünde yeterli şüphe oluşturmaları üzerine Cumhuriyet savcısınca şüpheli hakkında CMK'nın 170. maddesi uyarınca iddianamenin düzenlenmesiyle hukuki kesinti oluşmaktadır. İddianamenin düzenlenmesiyle olaylar arasında hukuki kesinti oluştuğundan iddianamenin düzenlenmesinden sonra devam eden eylemler ise başka bir ceza soruşturmasının konusunu oluşturacaktır. Baş-

Yeni TCK'nın 43. maddesine göre, örneğin hırsızlık suçuyla ilgili olarak zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için, bu suçun **aynı kişiye karşı** müteaddit defa işlenmesi gerekir¹²⁵⁷. Bu itibarla, **mağduru farklı kişiler olan müte-**

ka bir anlatımla sanık hakkında iddianame düzenlendikten sonra, sanık tarafından aynı suçun tekrar işlenmesi durumunda, yeni ve ayrı bir suç söz konusu olacaktır.

Buna karşın işlemiş olduğu suçtan dolayı henüz hakkında iddianame düzenlenmeden, sanığın aynı suç işleme kararıyla ve aynı mağdura karşı yeniden suç işlemesi durumunda, hukuki kesinti gerçekleşmeden aynı suçun işlenmesi söz konusu olduğundan sanık hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Bu ahvalde sanığın her suçtan ayrı ayrı cezalandırılması yoluna gidilmeyecek, sanığa bir suçtan ceza verildikten sonra hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle cezasından artırım yapılacaktır.

Buna göre, soruşturma aşamasında sanığın aynı suç işleme kararıyla, aynı mağdura karşı değişik zamanlarda aynı suçu işlediğinin tespit edilmesi durumunda, soruşturma dosyalarının birleştirilerek kamu davası açılması, bu hususa riayet edilmeden kamu davalarının açılması halinde ise hukuki kesintinin oluşmasından önce sanığın aynı mağdura karşı bir suç işleme kararıyla aynı suçu değişik zamanlarda işlediğinin anlaşılması durumunda dava dosyalarının birleştirilerek sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi isabetli bir uygulama olacaktır.

...

Bir suçun zincirleme biçimde işlendiğinin kabulü halinde, faile her bir suç için ayrı ayrı ceza verilmeyecek, tek bir ceza verilip bu ceza üzerinden TCK'nın 43/1. maddesi gereğince artırım yapılacaktır.

...

Zincirleme suça dâhil olan suçlardan biri hakkında beraat kararı verilmiş ya da zamanaşımı, genel af, şikâyetten vazgeçme gibi ceza ilişkisini ortadan kaldıran bir sebebe dayalı olarak hüküm kurulmuşsa artık o suç bakımından zincirleme suç ilişkisi kalkacağından henüz sonuca bağlanmayan suçla ilgili kesinleşen hükme konu fiil gözetilmeksizin bağımsız hüküm kurulmalıdır.

Zincirleme suça dâhil olan bir suçtan bu durum gözetilmeksizin mahkûmiyet kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmiş ise, zincirleme suça konu ikinci suçla ilgili olarak mahkemece; kesinleşen hükme konu eylem de göz önüne alınarak zincirleme suç hükümlerinin uygulanması suretiyle hüküm kurulmalı, kesinleşen hükümdeki ceza sonuç cezadan indirilmeli, böylece yargılaması devam eden suça ilişkin ceza belirlenmelidir.”; CGK, 15.3.2016, E. 2014/10-847, K. 2016/128. Ayrıca bkz. CGK, 16.5.2017, E. 2015/7-593, K. 2017/273; CGK, 16.5.2017, E. 2015/7-398, K. 2017/272.

Zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi gereken suçlardan biri veya birkaçı herhangi bir şekilde göz ardı edilerek, diğer suç veya suçlarla ilgili olarak mahkûmiyet hükmü kurulmuş ve kesinleşmiş ise, zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi gereken bir veya birkaç suçun işlendiğinin bilahare anlaşılması halinde, Ceza Genel Kurulu bu suç veya suçlar itibarıyla yeni bir mahkûmiyet hükmü kurulması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur. Söz konusu karar, bu yönü itibarıyla doğrudur. Ancak, bu kabule göre önceki mahkûmiyet hukuki varlığını devam ettirmektedir. Mahsupla mükerrer infazın önüne geçilmeye çalışılmakta ise de, fail hakkında bütün bu suçlar sebebiyle zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle artırılarak bir ceza verilmesi gerekirken, iki mahkûmiyet ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamanın mahkûmiyete bağlı hukuki sonuçlar ve tekerrür bakımından önemli sakıncalar ortaya çıkaracağını düşünmekteyiz.

Kanaatimizce söz konusu durumda, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilerek, önceki mahkûmiyet hükmü ortadan kaldırılmalı ve yeni bir mahkûmiyet hükmü tesis edilmelidir.

¹²⁵⁷ Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 5.2.2014 tarihli ve E. 2012/2733, K. 2014/1160 sayılı Kararına konu teşkil eden olay, şu şekilde cereyan eder:

addit hırsızlık suçlarıyla ilgili olarak zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Buna göre, bir otoparka bulunan farklı kişilere ait araçların kapı veya bagaj kapakları açılarak içlerinde bulunan muhtelif eşyanın çalınması halinde, mağdur sayısınınca hırsızlık ve mala zarar verme suçu oluşur.

Toplumu oluşturan **herkesin mağdur olduğu suçlarda**, zincirleme suç hükümlerini öncelikle uygulamak gerekir. Örneğin, rüşvet (m. 252), çevrenin kasten kirletilmesi (m. 181), imar kirliliğine neden olma (m. 184), parada sahtecilik (m. 197), kıymetli damgada sahtecilik (m. 199) ve mühürde sahtecilik (m. 202) gibi suçlarda, **belli bir kişi suçun mağduru değildir.** Bu suçların müteselsilen işlenmesi halinde, zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir. Bu hususa açıklık getirebilmek ama-

Cahit, 7 yaşındaki Gülçin ve 8 yaşındaki Nesibe'yi kandırarak ve doğum pastası alacağı vaadi ile çalıştığı işyerine gelmelerini sağlar ve işyerinden ayrılmamaları için bu çocuklara karşı zor kullanır; işyerinde alıkoyduğu bu iki çocuğa karşı cinsel istismar fiillerini gerçekleştirir.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cahit'in

- a) Gülçin ve Nesibe'ye karşı **cinsel istismar suçunu** (TCK, m. 103) işlediğini,
 - b) Bu suçu **vücuda organ sokmak suretiyle** işlediğini (TCK, m. 103, f. 2),
 - c) Bu suçu mağdur çocuklara **cebir veya tehdit kullanarak** işlediğini (TCK, m. 103, f. 4),
- kabul ederek ve cinsel istismarın **iki ayrı mağdura karşı** işlenmiş olması sebebiyle olayda **gerçek ıçtima** hükümlerini uygular ve Cahit hakkında **sonuç ceza** olarak (16+16=) **32 yıl hapis cezasına** hükmeder (21.11.2008 tarihli ve E. 2007/307, K. 2008/351 sayılı Karar).

Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay'ca onanan bu karar, 10.6.2009 tarihinde kesinleşir.

Mahkeme, bu olayda ayrıca her iki çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlendiğini kabul eder; ancak açılan davanın iddianamesinde bu suç sebebiyle sanığın cezalandırılması talep edilmediği için, sanık hakkında mahkumiyet kararı veremez; bu suç sebebiyle ayrı bir dava açılması için Ankara C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

Her iki çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlenmiş olduğu iddiasıyla açılan ikinci davada, **Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi,**

- a) Cahit hakkında, Gülçin ve Nesibe'ye karşı **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu** (TCK, m. 109) işlediğini kabul ederek; bu suçun **cebir, tehdit ve hile kullanarak işlenmiş olması** sebebiyle, temel ceza olarak 2 yıl hapis cezasına hükmeder.
- b) Bu suçun **çocuğa karşı işlenmiş olması**, mağdurun çocuk olması sebebiyle, 109. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen temel cezayı bir kat artırır (m. 109, f. 3, bent f).
- c) Bu suçun **cinsel amaçla işlenmiş olması** sebebiyle, üçüncü fıkra hükmü uygulanarak belirlenen 4 yıl hapis cezasını yarı oranında artırır (TCK, m. 109, f. 5).
- ç) Olayda TCK'nın 43. maddesinin ikinci fıkrası hükmünü uygulayarak, aynı suçun tek bir fiil ile iki ayrı kişiye karşı işlenmiş olması (**aynı neviden fikri ıçtima**) sebebiyle, 109. maddenin beşinci fıkrası uygulanarak belirlenen 6 yıl hapis cezasını takdire 1/4 oranında artırarak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeder (TCK, m. 43, f. 1, 2).

- d) Cahit hakkında **takdiri indirim sebeplerinin** (TCK, m. 62) varlığını kabul ederek, 7 yıl 6 aylık hapis cezasında 1/6 oranında indirim yapar ve **sonuç ceza** olarak, **6 yıl 3 ay hapis cezasına** hükmeder (30.06.2010 tarihli ve E. 2009/1072, K. 2010/510 sayılı Karar).

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, her iki mağdureye yönelik olarak işlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı, fail hakkında **gerçek ıçtima** hükümlerine göre cezaya hükmedilmesi gerekirken, *aynı neviden fikri ıçtima*ın varlığının kabulüyle **eksik ceza verilmiş olması sebebiyle**, Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinin kararını bozar.

cıyla, 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla 43'üncü maddenin birinci fıkrasına şu hüküm eklenmiştir: “Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.”. Bu değişiklikle ilgili **gerekçe** şu şekildedir¹²⁵⁸:

«Zincirleme suç hâlinde, aynı suçun birden fazla işlenmiş olması söz konusudur. Ancak, bu suçlar, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmektedirler, yani, bu suçlar arasında sübjektif bir bağ bulunmaktadır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Zincirleme suç halinde, ortada bir suç değil, birden fazla suç mevcuttur. Zincirleme suçtan söz edebilmek için, aynı suçun müteaddit defa aynı kişiye karşı işlenmesi gerekir. İşlenen suçların mağdurunun aynı kişi olması gerekir. Suçun mağdurunun farklı kişiler olması halinde, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Rüşvet ve çevrenin kirletilmesi gibi, toplumu oluşturan herkesin mağdur olduğu suçlarda, muayyen bir kişi mağdur olmadığına göre, zincirleme suç hükümlerini öncelikle uygulamak gerekir. Ancak, bu son durumla ilgili olarak hukuk uygulayıcılarında oluşan tereddüdü gidermek amacıyla, 43'üncü maddenin birinci fıkrasına “Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.” şeklinde bir cümle eklenmiştir.»

Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, **aynı suç** sayılır (m. 43, f. 1, üçüncü cümle)¹²⁵⁹.

Zincirleme suçun sübjektif koşulu ise, işlenen birden fazla suç arasında bir **manevi bağ**ın bulunmasıdır. Başka bir deyişle, bu fiiller, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmektedir.

Aynı suçun birden fazla işlenmesi halinde, bu suçlar arasında manevi bağın mevcut olup olmadığını, her bir olayın somut işleniş koşullarına göre takdir etme yetkisine sahip olan hakimdir^{1260, 1261}.

¹²⁵⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 2.

¹²⁵⁹ “Aynı suç” kavramı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: <https://izzetozgenc.com/data/contents/genel-olarak-hakaret-ve-cumhurbaskanina-hakaret-suclari-uzerine-degerlendirmeler.pdf> (Yayına giriş tarihi: 12.01.2022; Erişim tarihi: 18.07.2022).

<https://izzetozgenc.com/data/contents/cumhurbaskanina-hakaret.pdf> (Yayına giriş tarihi: 25.01.2022; Erişim tarihi: 18.07.2022).

¹²⁶⁰ «TC. Yasası, suçların edilgin özneleri başka başka oldukları takdirde, kesintili (müteselsil) suç hükmünün değil, gerçek (maddi) ictima hükümlerinin uygulanacağına ilişkin bir kural getirmemiş; birçok yabancı yasa gibi, yalnızca öznel (sübjektif) bir ölçüt öngörmüştür. Bu ölçüte göre, insana ilişkin varlık, değer ya da yararların çiğnenmesinde ve dolayısıyla edilgin özne çokluğunda bile, “bir (aynı) suç işleme kararıyla” davranılmışsa, “kesintili suç” hükmü uygulanabilecektir. Bunun tersini önceden bir yargısal kural (içtihat) boyutunda algılamak, Yasanın öngörmediği bir öğeyi TC. Yasasının 80. maddesine eklemek ve maddenin uygulama alanını daraltırmak demektir. Bu nedenlerle fiil ve suç (ihlal) çokluğunun varlığını saptadıktan sonra, kasıt kavramına oranla daha genel, geniş ve kapsayıcı bir kavram olan “bir (aynı) suç işleme kararı” olgusunun her olayda var olup olmadığını, bu olgu kişinin iç dünyasını ilgi-

Zincirleme suç halinde, kanunda suç olarak tanımlanan fiil birden fazla gerçekleştirilmektedir, yani aynı suç müteaddit defa işlenmektedir. Aslında her bir fiil ayrı bir suç oluşturduğu halde, kişiye bu suçların her birinden dolayı ayrı ayrı değil, **bir ceza** verilmekte ve fakat **ceza artırılmaktadır**.

Ancak, belirtilmelidir ki, bir suçun temel şekli ile daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinin müteselsilen işlenmesi halinde, **üzerinde artırma yapılması gereken ceza, suçun nitelikli şekline göre belirlenen ceza** olmalıdır.

Suçun müteselsilen işlenmesi halinde cezada yapılacak olan artırımla ilgili olarak tek bir oran belirlenmemiştir. Kanun koyucu, 61'inci madde hükümleri gereği izlenen sürece göre belirlenen cezanın “*dörtte birinden dörtte üçüne kadar*” artırılabilceğini öngörmüştür. Hakim, somut olayda müteselsilen işlenen suç sayısını göz önünde bulundurmak suretiyle, bu makas arasında belirleyeceği bir oranda cezayı artıracaktır.

Bir suçu oluşturan fiilin müteselsilen işlenmesi sürecinde Kanun koyucu bunun hukuki niteliğini değiştirerek başka bir suç oluşturduğu yönünde düzenleme yapabilir. Bu süreçte suç vasfında yapılan değişiklik, zincirleme suç olgusunun kabulüne engel değildir¹²⁶².

lendiren bir fiili sorun olduğundan, doğrudanlık, yüzyüzelik ve sözlülük kurallarına göre duruşma yapan ilk mahkemenin kararında irdelenmesi ve Yargıtay denetimini sağlayacak biçimde gerekçelendirilmesi zorunludur. Zira bu konuda Yargıtay, duruşma yapan ilk mahkemenin yerine geçemez. Yalnızca gerekçe denetimi yapılabilir. O kadar. “Bir suç işleme kararının” varlığını saptarken, mahkeme, her suç çokluğunda, kuşkusuz, fiillerin işleniş biçimlerindeki benzerlik ya da tekdüzelik, benzer fırsatları değerlendirme, yasa sistematığına göre suçla korunan hukuki varlık, değer ya da yarar, cürmi davranışın yöneldiği maddi konu olan kişi ya da şeyin özellik ve başkalıkları, suçlar arasındaki zaman aralığı ve bunlara benzer daha bir çok dışa yansıyan verilerden yararlanabilir ve bunlara dayanabilir.»: Sami Selçuk'un, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 3.12.1996 tarih ve 8022/9095 sayılı kararına muhalefet şerhi (YKD, Nisan 1997, sh. 618 vd.)

¹²⁶¹ “Asker kaçağı olan sanığın yakalanmamak amacıyla sahte olarak nüfus cüzdanı düzenleterek kullanması, daha sonra çalışmak amacıyla Irak'a gitmeye karar verince bu kez sahte nüfus cüzdanıyla uyumlu olacak şekilde sahte pasaport düzenleterek, sahte pasaportu yurt dışına gidiş ve dönüşte kullanması şeklinde gerçekleşen somut olayda, asker kaçağı olan sanığın başlangıçta yakalanmamak için sahte düzenlenmiş olan nüfus cüzdanını kullandığı, daha sonra ise çalışmak amacıyla yurt dışına gitmeye karar verince bu kez sahte olarak düzenlenmiş olan pasaportu kullandığı sabittir.

Bu durumda sanığın başlangıçta, **asker kaçağı olduğu için yakalanmamak amacıyla** sahte nüfus cüzdanı kullandığı, daha sonra ise **yurt dışına çalışmak için gidebilmek amacıyla** sahte pasaport kullandığı anlaşılmakta olup, her iki suça ilişkin kasttan önce gelen genel bir niyet ve bir suç işleme kararının varlığından, diğer bir deyişle iki suçu ortak bir zemine taşıyan subjektif bir bağdan söz etmek mümkün değildir. Zira sanık yeni bir sebep ortaya çıktıkça sahte belge düzenleterek kullanmış ve her bir olay için yenilenmiş bir suç işleme kararı ile hareket etmiş olduğundan, zincirleme suç hükümlerinin uygulanma imkanı bulunmayıp, işlenmiş iki ayrı sahtecilik suçunun söz konusu olduğu ve her iki suçtan da ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği kabul edilmelidir.” CGK, **21.1.2014**, E. 2013/9-593, K. 2014/24.

¹²⁶² İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER: Suç Teorisi, 2. Kitap, 2. bası, İstanbul 2000, sh. 443.

Örneğin özel hukuk tüzel kişisi olan banka kaynaklarının yönetici konumundaki kişiler tarafından zimmete geçirilmesi, 765 sayılı TCK'ya göre (m. 508 ve 510) “hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal” suçunu oluşturmaktaydı. Ancak, 23.6.1999 tarih ve 23734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 Haziran 1999 tarihli ve 4389 sayılı **Bankalar Kanununun** 22. maddesinin 3 numaralı fıkrasında ise, aynı fiiller özel bir zimmet suçu olarak tanımlanmıştır. Söz konusu fiiller, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı **Bankacılık Kanununun** 160 ncı maddesinde de özel bir zimmet suçu olarak tanımlanmıştır¹²⁶³.

¹²⁶³ A, henüz on yedi yaşında olan ve zekâ geriliği bulunan üvey kızı B'yi cinsel yönden istismar eder. A, bu ilişkinin açığa çıkmaması için B'ye karşı şiddet kullanır ve evden dışarı çıkmasını engellemeye yönelik tedbirler alarak kızı eve hapseder. Bu cinsel ilişki, B'nin on sekiz yaşını tamamlamasından sonra da bir süre devam eder.

I. Olay sırasında on beş yaşını tamamlamış olmakla birlikte, B'nin, zekâ geriliği sebebiyle, maruz bırakıldığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiştir. Bu itibarla B, TCK, m. 103, f. 1, bent a kapsamına girmektedir.

Bu olayda A, B'ye karşı, TCK'nın “**Çocukların cinsel istismarı**” başlıklı 103. maddesinin **ikinci fıkrası** kapsamına giren istismar suçunu işler. Bu nedenle, A hakkında **temel ceza**, TCK, m. 103, f. 2 hükümlerine göre belirlenecektir.

Bu suç, **üvey baba** tarafından işlendiği için, A hakkında TCK, m. 103, f. 2'ye göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılır (TCK, m. 103, f. 3, bent c).

A'nın, bu suçu işlemeye devam edebilmek için, B'ye karşı şiddet kullanması, yani istismar fiilini **cebir ve tehditle** işlemiş olması sebebiyle, TCK, m. 103, f. 2 ve 3 uygulanmak suretiyle belirlenen ceza, yarı oranında artırılır (TCK, m. 103, f. 4).

A, bu suçu işlemeye B henüz on yedi yaşında iken başlar ve on sekiz yaşını tamamlayıncaya kadar devam eder. On sekiz yaşını tamamlanmasından itibaren bu cinsel ilişkinin bir süre daha devam etmesi, ayrıca değerlendirilecektir.

Bu devam olgusu, cinsel istismar suçundan dolayı A hakkında **zincirleme suç** hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. Başka bir ifadeyle, TCK, m. 103 hükümleri uygulanmak suretiyle A hakkında belirlenen cezanın TCK, m. 43, f. 1 hükümlerine istinaden artırılması gerekmektedir.

II. A ayrıca, B'ye karşı, **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma** suçunu işler (TCK, m. 109, f. 1).

Ancak A, bu suçun işlenmesi sırasında B'ye karşı **şiddet (cebir)** kullanır. Bu nedenle, A hakkında söz konusu suçtan dolayı **temel ceza**, TCK, m. 109, f. 2 hükümlerine göre belirlenecektir.

Üst soy, üvey babayı kapsamamaktadır. Bu nedenle, A hakkında TCK, m. 109, f. 3 bağlamında yapılan değerlendirmede, e bendi dikkate alınamaz. Ancak, mağdur B, **zekâ geriliği olan** bir **çocuk** olduğu için, f bendini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu itibarla, A hakkında TCK, m. 109, f. 2 hükümleri uygulanmak suretiyle belirlenen temel ceza, bir kat artırılır (TCK, m. 109, f. 3).

Keza, söz konusu suçun **cinsel amaçla** işlenmiş olması sebebiyle, A hakkında TCK, m. 109, f. 2 ve 3 hükümlerine göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır (TCK, m. 109, f. 5).

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, cinsel istismar suçunun bir unsurunu veya nitelikli halini oluşturmadığı için, A hakkında her iki suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekecektir (**gerçek içtima**).

III. Yukarıda da belirtildiği gibi, A, B'ye karşı cinsel istismar suçunu işlemeye B henüz on yedi yaşında iken başlamış ise de, on sekiz yaşını tamamlamasından sonra bir süre daha B ile cinsel

Bu kanuni düzenlemeyle bir fiilin nitelendirilmesinde değişiklik yapılması, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yeni TCK'nın 43. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, aynı kişiye karşı müteaddit defa işlenen **kasten yaralama, işkence ve yağma** suçlarında, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Bu suçlarda, fail işlediği suç sayısınca gerçek içtima hükümlerine göre cezalandırılacaktır (m. 43, f. 3).

Maddenin üçüncü fıkrasında cinsel saldırı (m. 102) ve çocukların cinsel istismarı (m. 103) suçları da bu istisnalar arasında sayılmıştı. Yeni TCK'ya ilişkin TBMM Adalet Komisyonunda yapılan çalışmalar sırasında, bu suçların aynı kişiye karşı müteaddit defa işlenmesi halinde gerçek içtima hükümlerinin uygulanmasının kabulünün ispat sorununa neden olacağı yönünde itirazlarımıza rağmen, bu iki istisna, Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın isteği üzerine madde metnine konmuştu. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak yürütülen yeni ceza kanunlarıyla ilgili bilgilendirme faaliyeti sırasında, bu istisna hükmü eleştirilmiştir. Bu eleştiriler de dikkate alınmak suretiyle, 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla 43'üncü maddenin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Böylece, cinsel saldırı (m. 102) ve çocukların cinsel istismarı (m. 103) suçlarının aynı kişiye karşı müteaddit defa işlenmesi halinde de zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir. Bu değişiklikle ilgili **gerekçe** şu şekildedir:

«Zincirleme suç halinde, kişiye bu suçların her birinden dolayı ayrı ayrı değil, bir ceza verilmekte ve fakat ceza artırılmaktadır. Ancak, cinsel sal-

ilişkide bulunmaya devam eder. A'nın, on sekiz yaşını tamamladıktan sonra da B ile cinsel ilişkiye devam etmesi, ayrı bir suç olarak "**Cinsel saldırı**" suçunu (TCK, m. 102) oluşturur.

Ancak, A'ya bu suç sebebiyle verilecek **temel ceza**, 102. maddesinin **ikinci fıkrası** hükümlerine göre belirlenecektir.

Bu suç, zekâ geriliği bulunan, yani **ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı** işlenmiştir (TCK, m. 102, f. 3, bent a).

Bu suç, **üvey baba** tarafından işlenmiştir (TCK, m. 102, f. 3, bent c).

Bu nedenle, A hakkında TCK, m. 102, f. 2 hükümlerine göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılır (TCK, m. 102, f. 3).

Cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçuna nazaran daha az ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir suç mahiyeti taşımaktadır.

Olayda zincirleme olarak işlenen fiiller önce cinsel istismar suçunu, bilahare ise, cinsel saldırı suçunu oluşturmaktadır. Bu durumda, hafiften daha ağıra doğru değil, ağırdan daha hafife doğru işleyen bir süreç söz konusudur. Her iki suçu oluşturan fiillerin aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlendiğinde kuşku bulunmamaktadır. Her ne kadar, mağdurun on sekiz yaşını tamamlamasından sonraki fiiller, cinsel istismar suçunu değil de, cinsel saldırı suçunu oluştursa bile; **işlenen fiillerin doğal mahiyetinde bir değişiklik söz konusu değildir**. Bu nedenle olayda, A hakkında cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek (gerçek içtima) yerine, **zincirleme suç** hükümlerini uygulayarak, **cinsel istismar suçundan dolayı belirlenen cezanın** TCK, m. 43, f. 1 hükümlerine göre **artırılmasının** daha doğru olacağını düşünmekteyiz.

dırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarının aynı kişiye karşı müteaddit defa işlenmesi halinde gerçek içtima hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündeki düzenleme, başta Yargıtay olmak üzere hâkim ve savcılarda ispat sorunu ve ölçüsüz ceza miktarlarının ortaya çıkması bakımından ciddi endişelere neden olmuştur. Bu endişeleri gidermek amacıyla, maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı" ibaresi metinden çıkarılmıştır.»¹²⁶⁴

Yargıtay kararlarında belgede sahtecilik suçu bağlamında suçların içtimai hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki örnekler çerçevesinde açıklama yapma lüzumu hissetmiş bulunmaktayız:

Örnek 1. A, B'ye ait çek defterini hukuka aykırı bir yolla elde eder ve borçlandığı üç farklı kişiye borçlarına karşılık olarak bu çek defterinden çek düzenleyerek verir.

Bu olayda A'nın B'ye ait çek defterini hukuka aykırı yolla ele geçirmesi, **hırsızlık** (TCK, m. 141 vd.) veya başkasına ait **kaybolmuş eşya üzerinde tasarrufta bulunma** (TCK, m. 160) suçunu oluşturur.

Keza, A'nın borçlandığı kişilere B adına çek düzenleyerek vermesi, **dolandırıcılık** (TCK, m. 157 vd.) suçunu oluşturur. Bu bağlamda **dolandırılan kişi sayısınca dolandırıcılık suçu** oluşur ve A'nın bu suç nedeniyle **gerçek içtima** hükümlerine göre cezalandırılması gerekir. Başka bir ifadeyle, bu durumda, mülga 765 s. TCK'nın 80. maddesine nazaran, 5237 s. TCK'nın 43. maddesi hükümlerine göre **zincirleme suç hükümleri uygulanamaz**.

TCK'nın 212. maddesi hükmü karşısında, dolandırıcılık suçunun icrası bağlamında belgede sahtecilik suçunun işlenmiş olması durumunda, failin **ayrıca belgede sahtecilik suçu** nedeniyle cezalandırılması gerekir. Çek, bir kambiyo senedidir. Bu itibarla, sahte çek düzenlenmesi halinde, failin özel belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlere (TCK, m. 207) göre değil, **resmi belgede sahtecilik** suçuna ilişkin hükümlere (TCK, m. 204) göre cezalandırılması gerekir (TCK, m. 210, f. 1). Bu itibarla, A'nın ayrıca resmi belgede sahtecilik suçu dolayısıyla cezalandırılması gerekir ve A hakkında bu suç bağlamında **zincirleme suç hükümlerinin** (TCK, m. 43, f. 1) uygulanması gerekir.

Örnek 2. A, üyesi bulunduğu kooperatife, üyelik borçlarına karşılık olarak ileri tarihli ve birer aylık farklı tarihleri içeren üç adet çek düzenleyerek verir. Bu çeklerin bilahare sahte olduğu anlaşılır.

Bu olayda, A'nın **fiili dolandırıcılık suçunu oluşturmaz**. Çünkü düzenlediği sahte çekleri kooperatife vermiş olmakla bir haksız menfaat elde etmiş değildir. Ancak, sahte kambiyo senedi (çek) düzenlemiş olması dolayısıyla A'nın **resmi belgede sahtecilik suçuna** ilişkin hükümlere göre cezalandırılması gerekir.

¹²⁶⁴ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 2/3.

Dikkat edilmelidir ki, bu olayda üç ayrı sahte çek düzenlenerek, **konuları birbirinden farklı olan birden fazla belgede sahtecilik suçu** işlenmiştir. Bu sahte çekler, bir fiil ile işlenmemiştir. Olayda her bir sahte çekin düzenlenmesi bağlamında ayrı fiil mevcuttur. Bu fiillerin işlenişi arasında çok kısa da olsa bir zaman fasılası mevcuttur. Ancak, bu sahtecilik fiillerini bir suç işleme kararı kapsamında işlemiş olduğu için, A hakkında **zincirleme suç** hükümlerinin (TCK, m. 43, f. 1) uygulanması gerekir.

Ancak Yargıtay, mülga 765 s. TCK'nın yürürlükte olduğu dönemde özellikle belgede sahtecilik suçu ile ilgili paçal cezalandırma yönteminin etkisiyle, bu tür olaylarda, fiilin değişik zamanlarda değil aynı zamanda işlendiği gerekçesiyle, bir belgede sahtecilik suçunun oluştuğu ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur¹²⁶⁵,¹²⁶⁶.

¹²⁶⁵ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **8.6.2010** tarihli ve E. 2010/11-98, K. 2010/143 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, sanık C, müşteki ve katılan S'den aldığı iki farklı keşide tarihli çekin her ikisinin de keşide tarihini değiştirir ve arkasını ciro ederek G'ye verir.

Esas Mahkemesi, C'yi resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı zincirleme suç hükümlerini uygulayarak mahkum etmiştir. Bu Karar, Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise, yeni TCK'nın 43. maddesinin birinci fıkrasında 765 s. Mülga TCK'nın 80. maddesine nazaran "değişik zamanlarda" ibaresine yer verilmiş olması dolayısıyla, olayda zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gerekçesiyle bu karara itiraz etmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'da, aşağıdaki gerekçe ile, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının kabulüne, 11. Ceza Dairesinin onama kararının kaldırılmasına ve Esas Mahkemesinin mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir:

"sanığın suça konu iki adet çek yaprağı üzerindeki sahteciliği de dosya içeriği karşısında aynı zaman dilimi içinde gerçekleştirdiğinin kabulü gerekmektedir.

... İki adet çek yaprağı üzerinde aynı zaman diliminde yapılan sahtecilikten dolayı sanık hakkında ... 5237 sayılı TCY'nın 43/1 maddesi, madde metninde yer alan "*değişik zamanlarda*" ibaresi nedeniyle uygulanmamalı, ancak bununla birlikte birden fazla çek yaprağı üzerinde sahtecilik yapılmış olması Yasanın 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesi sırasında gözönüne alınmalıdır."

Yukarıda açıkladığımız gerekçe ile bu **kararın doğru olmadığını** düşünmekteyiz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu Kararında yer verilen, fiil ile neticenin eşanlamli kavramlar olduğu izlenimi uyandıran şu açıklamaların doğru olmadığı ortadadır:

"Ceza hukukunda yasadaki suç tanımına uygun olarak gerçekleşen her netice ilke olarak ayrı bir suç oluşturur ve fail kaç netice meydana getirmiş ise o kadar suç işlemiş sayılarak her birinden dolayı ayrı ve bağımsız cezalandırılır. Ancak bazı hallerde birden fazla netice meydana gelmiş olsa bile, faile meydana gelen netice kadar ceza verilmeyerek tek bir ceza verilmesi ile yetinilir. **Birden fazla neticenin meydana gelmesine karşın faile tek ceza verilmesini gerektiren hallerden biri de zincirleme suçtur.** Zincirleme suçta faile tek ceza verilirken, yasanın öngördüğü miktarda bir artırım da yapılması söz konusudur."

¹²⁶⁶ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **13.3.2012** tarihli ve E. 2011/6.MD-236, K. 2012/86 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi H, nüfus kaydının düzeltilmesi talebiyle açılan beş davanın duruşmasını, Cumhuriyet savcılarına haber vermeden ve onları katılmış gibi göstererek yapar; duruşma tutanaklarına Cumhuriyet savcılarının adına görüş yazdırarak hüküm kurar.

Örnek 3. A'ya ait nüfus kayıtlarında gerçeğe aykırı olarak değişiklik yapılır. Bu değişikliğe paralel olarak A'ya sahte bir nüfus cüzdanı düzenlenir.

Bu olayda aynı kişi ile ilgili de olsa **iki ayrı belgede** sahtecilik yapılmış ve **resmi belgede sahtecilik suçu** (TCK, m. 204) **iki defa** işlenmiştir. Ancak, bu sahtecilik fiilleri bir suç işleme kararı kapsamında işlenmiş olduğu için, olayda **zincirleme suç hükümlerinin** (TCK, m. 43, f. 1) uygulanması gerekir¹²⁶⁷.

Ancak Yargıtay, bu tür olaylarda da, fiilin değişik zamanlarda işlendiğini gösterir somut vakıaların bulunmaması sebebiyle, aynı zamanda işlendiğinin kabulüyle bir belgede sahtecilik suçunun oluştuğu ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

Yargıtay **Ceza Genel Kurulu'nun 4.10.2011** tarihli ve E. 2011/8-115, K. 2011/197 sayılı Kararına konu teşkil eden olay şu şekilde cereyan eder:

30.4.2006 tarihinde yapılan kontrolde ÖA'nın kullandığı kamyonete takılı bulunan 34 AV 7590 numaralı plaka ile bu araçla ilgili olarak düzenlenmiş olan trafik tescil belgesinin sahte olduğu anlaşılar.

13.4.2006 tarihinde İstanbul'da çalındığı anlaşılan ve gerçek plakası 34 VPA 83 olan araç, ÖA tarafından C'den 29.4.2006 tarihinde, söz konusu sahte plaka ve sahte tescil belgesine istinaden satın alınır.

Söz konusu kararda Yargıtay, motorlu araç plakası üzerinde yapılan sahteciliğin, aşağıya iktibas etmiş bulunduğumuz gerekçeyle, TCK'nın **resmi belgede sahtecilik suçu** kapsamında değerlendirilmesi gerektiği içtihadında bulunmuştur.

“5237 sayılı TCK'nın 204. maddesinin gerekçesinde; “... Ayrıca belirtilmelidir ki, her ne kadar, belgeden söz edilen durumlarda yazılı bir kağıdın varlığı gerekli ise de; bazı durumlarda belgenin varlığını kabul için, yazının kağıt üzerinde bulunması gerekmez. Bir metal levha üzerine yazı yazılması halinde de belgenin varlığını kabul etmek gerekir. Bu itibarla, araç plakaları da resmi belge olarak kabul edilmek gerekir” şeklindeki anlatım ile **araç plakalarının da resmi belge olarak kabul edileceğinin** açıkça belirtilmiş olması karşısında, ...

Bu olayla ilgili olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu aşağıdaki hukuki değerlendirmede bulunur:

“Sanık hâkimin, Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen, **2001/888, 752, 1072, 1073 ve 1053 esas sayılı nüfus düzeltme davalarında C.Savcısını duruşmada hazır gösterip, adına mütalaa yazdırıp ve bu doğrultuda hüküm kurduğu, sanığın olaylardaki davranış biçimi, eylemler arasındaki zaman süreci, suçla korunan hukuki yarar, suçun aynı mağdura karşı işlenmesi birlikte değerlendirildiğinde, sanığın aynı suç işleme kararıyla zincirleme şekilde sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgede sahtecilik suçunu işlediğinin kabulü gerekmektedir.**”

¹²⁶⁷ Buna karşılık, A'ya ait sadece nüfus kayıtlarında veya nüfus cüzdanında sahtecilik yapılmış olsa idi, **resmi belgede sahtecilik suçunun** (TCK, m. 204) **bir defa** işlenmiş olduğunu kabul etmek gerekirdi.

sahte plaka kullanma eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.”

Bu kabulün doğru olduğunu belirtmek gerekir.

Söz konusu Kararda ayrıca, sahte plakayla birlikte sahte trafik tescil belgesinin düzenlenmiş olması durumunda, resmi belgede sahtecilik suçunun bir defa işlenmiş olduğundan bahisle mi yoksa bu suçun müteselsilen iki defa işlenmiş olması dolayısıyla zincirleme suç hükümlerine göre mi cezaya hükmedilmesi gerektiği tartışılmıştır.

Bu tartışma sonucunda, aşağıdaki gerekçeyle olayda resmi belgede sahtecilik suçunun **bir defa** işlenmiş olduğu ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması gerektiği içtihadında bulunulmuştur:

“Zincirleme suç, 765 s. TCK'nın 80. maddesinde; *“Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün bir kaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır”* şeklinde düzenlenmişken, 5237 sayılı Yasanın 43/1. maddesinin konumuza ilişkin ilk cümlesinde; *“Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir”* biçiminde düzenlenmiştir.

765 s. TCK'da yer alan *“muhtelif zamanlarda vaki olsa bile”* ifadesinden hareketle aynı suç işleme kararı altında birden fazla suçun aynı zamanda işlenmesi durumunda diğer koşulların da varlığı halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi olanaklıdır. 5237 sayılı TCY'nın 43/1. maddesinde bulunan *“değişik zamanlarda”* ifadesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için, suçların mutlaka değişik zamanlarda işlenmesi gereklidir ki bunun sonucu olarak, aynı mağdura, aynı zamanda, aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda tek suçun oluşacağı kabul edilmiştir. Bu halde zincirleme suç hükümleri uygulanarak artırım yapılamayacak, ancak bu husus 5237 sayılı TCY'nın 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesinde göz önüne alınabilecektir.”

Belirtmemiz gerekir ki, söz konusu kararda sorun **yanlış** bir zeminde tartışılmıştır.

Bir araca ilişkin trafik kayıtları, trafik sicilineki kayıtlar, tescil belgesi ve plakadan müteşekkildir. Bir araca ilişkin trafik kayıtlarının bu üç unsurundan sadece birinde sahtecilik yapılabileceği gibi, her üçünde de sahtecilik yapılabilir.

Örneğin, bir araca ilişkin trafik sicilineki kayıtlarda yer alan rehin şerhinde veya araçla ilgili olarak verilmiş elkoyma kararı şerhinde sahtecilik yapılması halinde, resmi belgede sahtecilik suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.

Keza, araca ilişkin trafik tescil belgesi üzerindeki motor şasi numarasında değişiklik yapılması veya araç üzerinde takılı bulunan plakanın sahte olarak tanzim edilmiş olması halinde, diğer trafik kayıtları gerçeğe uygun olsa bile, bir belgede sahtecilik suçu mevcuttur.

Motorlu araca ilişkin trafik sicilineki kayıtlarda, tescil belgesinde ve plakada sahtecilik yapılmış olabilir. Örneğin yurda kaçak olarak sokulan veya hırsızlık

suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen araç, meşru yolla elde edilmiş izlenimi uyandıracak şekilde düzenlenen sahte belgeler mesnet gösterilerek trafiğe tescil edilmiş, bu araçla ilgili olarak sahte tescil belgesi ve plaka düzenlenmiş olduğunda, **sahte olarak düzenlenen belge sayısınca resmi veya özel belgede sahtecilik suçunun işlendiğini kabul etmek gerekir.**

Bu gibi durumlarda, fiil tek olmadığı için TCK'nın 43. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen aynı neviden fikri içtima hükümleri uygulanamaz.

Bu tür olaylarda bir adet resmi veya özel belgede sahtecilik suçunun işlendiği ve zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanmaması gerektiği yönündeki Yargıtay içtihadını doğru bulmuyoruz^{1268, 1269}.

¹²⁶⁸ Üzerinde sahte plaka takılı vaziyette ve sürücüsü beraberinde sahte trafik tescil belgesi bulunduğu halde araç trafiğe çıkarıldığında, resmi belgede sahtecilik suçu seçimlik hareket olarak kullanmak suretiyle işlenmektedir. Bu durumda kullanma olgusu devam ettiği sürece resmi belgede sahtecilik suçunun kesintisiz (mütemadi) suç olarak işlenmekte olduğunu kabul etmek gerekir.

İnceleme konumuzu oluşturan Yargıtay kararlarında resmi belgede sahtecilik suçunun kullanmak suretiyle işlenmesine yönelik herhangi bir açıklamada bulunulmamaktadır.

¹²⁶⁹ Aynı yanlışlık, Ceza Genel Kurulunun bilahare verilen değişik kararlarında da mevcuttur.

Ceza Genel Kurulu'nun **18.12.2012** tarihli ve E. 2012/11-999, K. 2012/1862 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, RB, 13.2.2006 tarihinde kendisine ait gerçek pasaportu kullanarak Atatürk Havalimanından çıkış yapar. RB, İtalya'nın Milano Havalimanına ulaştıktan sonra Fransa'ya gidebilmek için havalimanından çıkış sırasında "Adem Meral" adına düzenlenmiş sahte hususi (yeşil) pasaportu kullanmak ister. Ancak İtalyan görevlilerce pasaportun sahte olduğu fark edilir ve RB sınırışı edilerek Türkiye'ye gönderilir.

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarının 15.2.2006 gün ve 898 sayılı Raporunda; "Adem Meral" adına düzenlenmiş TR-B-208608 seri nolu T.C. Hususi Pasaportunun 3. sayfasındaki fotoğrafın sökülerek RB'nin fotoğrafının yapıştırıldığı, 50. sayfadaki 90 nolu çıkış mühür izi ile 51. sayfasındaki iki çıkış mühür izlerinin sahte olduğu, ayrıca yurtdışı çıkış pulunun da başka bir yerden sökülerek buraya yapıştırıldığı, yine RB'nin fotoğrafını taşıyan F-09/6401483 seri numaralı nüfus cüzdanının ise tamamen sahte olarak üretildiği, her iki belgenin de iffal kabilinin bulunduğu, belirtilir.

Bu olayla ilgili olarak CGK şu kararı vermiştir:

"Sanığın, kendisi tarafından hazırlandığına dair delil ve iddia bulunmayan **sahte pasaport ve nüfus cüzdanını** aynı anda kullandığı hususunda bir uyumsuzluk bulunmadığına göre, suçun değişik zamanlarda işlenmemiş olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 43/1. maddesinin uygulanma şartları oluşmamıştır. Ancak bununla birlikte birden fazla sahte evrakın kullanılmış olması olgusu aynı Kanunun 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesi sırasında göz önüne alınmalıdır."

İşaret etmemiz gerekir ki, bu olayda **iki ayrı resmi belgede sahtecilik suçu** işlenmiştir. Bu durumda, aynı neviden fikri içtima hükümleri uygulanamaz ise de, zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilir olduğunu düşünmekteyiz.

İlginçtir ki, bu Karara muhalefet eden Genel Kurul üyelerinden biri, RB'nin önce "*bir resmi belgeyi (pasaportu) sahte olarak düzenleyen*", daha sonra da bu pasaportu havaalanında yurt dışına çıkışta kullanarak "*sahte resmi belgeyi kullanan kişi*" olarak TCK'nın 204. maddesinde tanımlanan resmi belgede sahtecilik suçunu "iki kez" işlediğini ve bu nedenle hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğini savunmuştur. Belirtmemiz gerekir ki, bu düşünce, seçimlik hareketli suç kavramından habersiz olarak oluşturulmuştur.

Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun **24.9.2013** tarihli ve E. 2012/11-1506, K. 2013/391 sayılı Kararına konu teşkil eden olay şu şekilde cereyan eder:

S, hacizli olan aracını sahte plaka ve tescil belgeleri ile kullanırken yakalanmıştır. Araçla ilgili plakalar ile trafik-tescil belgeleri tümünden sahte olarak oluşturulmuştur. S ifadesinde, yakalandığı tarihten altı ay kadar önce İstanbul'da tanımadığı bir şahsa para karşılığında suça konu plaka ve tescil belgelerini yaptırdığını, yakalandığı ana kadar da bu plaka ve ruhsat ile aracını kullandığını, ekonomik olarak zor durumda olduğu için bu şekilde hareket ettiğini beyan etmiştir.

Bu olayla ilgili olarak söz konusu Kararda şu tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

Resmi belgede sahtecilik suçunun temel şekli TCK'nın 204/1. maddesinde; *"Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır"* biçiminde düzenlenmiştir.

Suçun konusu resmi belgedir. Suçla korunan hukuki yarar ise kamu güveni olup, suçun mağduru da **toplumu oluşturan tüm bireylerdir**. Bununla birlikte suçun işlenmesiyle haksızlığa uğrayan gerçek ve tüzel kişilerin suçtan zarar görmeleri mümkün olduğundan, gerçek ve tüzel kişiler de yargılamaya katılabileceklerdir.

Resmi belgede sahtecilik suçu **seçimlik hareketli bir suç** olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik hareket, resmi belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Bu seçimlik hareketle, resmi belge esasında mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir. İkinci seçimlik hareket, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmektir. Bu seçimlik hareketle, esasında mevcut olan resmi belge üzerinde silmek veya ilaveler yapmak suretiyle değişiklik yapılmaktadır. Birinci ve ikinci seçimlik hareketle bağlantılı olarak belirtmek gerekir ki; sahteciliğin, belge üzerindeki bilgilerin bir kısmına veya tamamına ilişkin olmasının, suçun oluşması açısından bir önemi bulunmamaktadır. Üçüncü seçimlik hareket ise, sahte resmi belgeyi kullanmaktır. Kullanılan sahte belgenin kişinin kendisi veya başkası tarafından düzenlenmiş olmasının bir önemi yoktur. **Kullanma müttemadi suç şeklinde de gerçekleşebilir.**

Suçun oluşabilmesi için düzenlenen veya değiştirilen ya da kullanılan belgenin, gerçek bir belge olduğu konusunda kişiyi yanıltıcı nitelikte olması gerekir. Aldatıcılık özelliği bu suçun temel unsuru olup, özel bir incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılamayan belge, sahte belge olarak kabul edilmelidir. Sahteciliğin kişileri aldatacak nitelikte (nesnel) olup olmadığı ve beş duyuyu ilk bakışta anlaşılabilir olup olmadığı, şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.

5237 sayılı TCK'na hakim olan ilke gerçek içtimadır. Bunun sonucu olarak, *"kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza"* söz konusu olacaktır. Nitekim bu husus Adalet Komisyonu raporunda da; *"Ceza hukukunun temel kurallarından birisi, 'kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır' şeklinde ifade edilmektedir. Bunun istisnaları, suçların içtimai bölümünde belirlenmiştir. Bu istisnalar dışında, işlenen her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir. Böylece verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır"* şeklinde ifade edilmiştir. Bu kuralın istisnalarına ise, 5237 sayılı TCK'nın "suçların içtimai" bölümünde, 42 (bileşik suç), 43 (zincirleme suç) ve 44. (fikri içtima) maddelerinde yer verilmiştir.

Zincirleme suç, 765 sayılı TCK'nın 80. maddesinde; *"Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün bir kaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır"* şeklinde düzenlenmişken, 5237 sayılı TCK'nın 43/1. maddesinde; *"Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır"* biçiminde düzenlenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 43/1. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için;

- a)- Aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi,
- b)- İşlenen suçların mağdurlarının aynı kişi olması,
- c)- Bu suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmesi gerekmektedir.

765 sayılı TCK'da yer alan “*muhtelif zamanlarda vaki olsa bile*” ifadesi karşısında, aynı suç işleme kararı altında birden fazla suçun aynı zamanda işlenmesi durumunda diğer şartların da varlığı halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi mümkündür. Nitekim, 765 sayılı TCK'nın yürürlüğü zamanında bu husus yargısal kararlarla kabul edilmiş ve uygulama bu doğrultuda yerleşmiştir.

5237 sayılı TCK'nın 43/1. maddesinde bulunan “*değişik zamanlarda*” ifadesinin açıklığı karşısında, zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için **suçların farklı zamanlarda işlenmesi gerektiği konusunda öğreti ve uygulamada tam bir görüş birliği bulunmaktadır**. Bunun sonucu olarak, **aynı mağdura, aynı zamanda, aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda tek suçun oluşacağı** kabul edilmiştir. Bu halde zincirleme suç hükümleri uygulanarak artırım yapılamayacak, ancak bu husus TCK'nın 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.

Ayrıca, kanunda “*aynı zaman*” ve “*değişik zaman*” kavramları konusunda bir açıklık olmadığından ve önceden kesin belirlenmelerin yapılması da mümkün bulunmadığından, bu husus her somut olayın özelliği göz önüne alınarak değerlendirilmeli ve eylemlerin “*değişik zamanlarda*” işlenip işlenmediği belirlenmelidir.

Uyuşmazlığın çözümü açısından “*aynı suç*” kavramı da irdelenmelidir.

Aynı suç; 5237 sayılı TCK'nın 43. maddesinde “*bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır*” demek suretiyle açıklığa kavuşturulmuştur. Öğretide de “*aynı suçtan anlaşılması gerekenin, aynı suç tipi olduğu*”, kanunda düzenlenen suçların ismi aynı ise aynı suçtan söz edileceği, suçun ismi farklı ise artık aynı suçtan bahsedilemeyeceği kabul edilmektedir. Buna göre suçların ismi aynı ise aynı suçtan söz etmek mümkün iken, suçun ismi değiştiğinde artık aynı suçtan bahsetmek mümkün değildir. Örneğin dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık eylemleri aynı suç sayılır iken, dolandırıcılık ile güveni kötüye kullanma, hırsızlık ile dolandırıcılık, hırsızlık ile suç eşyasını satın alma aynı suç kavramı içerisinde değerlendirilemeyecektir. Aynı suç kavramına, suçun teşebbüs aşamasında kalmış hali de dahildir. Zincirleme suç oluşturan eylemlerden bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, işlenen suçların isimleri değişmediği sürece, aynı suç sayılacaktır.

Konunun açıklığa kavuşturulabilmesi için **mağdur** kavramının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Mağdur; Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde, “*haksızlığa uğramış kişi*” olarak tanımlanmaktadır. Ceza hukukunda ise mağdur kavramı, suçun konusunun ait olduğu kişi ya da kişilerdir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun hazırlanmasında esas alınan suç teorisinde **suçun maddi unsurları arasında yer alan mağdur, ancak gerçek bir kişi olabilecektir, tüzel kişilerin suçtan zarar görmeleri mümkün ise de bunlar mağdur sayılamayacaklardır**. Suçtan zarar gören ile mağdur kavramları da aynı şeyi ifade etmemektedir. Mağdur suçun işlenmesiyle her zaman zarar görmekte ise de, suçtan zarar gören kişi her zaman suçun mağduru olmayabilir. Bazı suçlarda mağdur belirli bir kişi olmayıp, toplumu oluşturan herkes (geniş anlamda mağdur) olabilecektir.

Zincirleme suçu oluşturan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi gerekir. Muhtelif suçları birbirine bağlayan, birleştiren ve müteselsil suçu yapısal olarak cezaların içtimaindan ayıran da bu şarttır. Bu sübjektif şart, “aynı suç kasdı” olarak anlaşılmamalıdır. Her biri bağımsız olan ve ayrı ayrı kastlarla işlenen bu suçların, aynı kastın ürünü olduklarını söylemek, mümkün değildir. Bir suç işleme kararından kanunun aynı hükmünü birkaç defa ihlal etmek hususunda önceden kurulan bir plan, genel bir niyet anlaşılmalıdır. Fail, önceden belirlediği böyle bir plân veya niyet kapsamında, bunu bir defada gerçekleştirmek yerine, kısımlara bölmeyi ve o suretle gerçekleştirmeyi daha uygun görmüş ve bu plâna göre hareket etmiş olduğundan, birden fazla olan kısımlar, yani ayrı suçlar, tek bir müteselsil suç meydana getirirler.

...

IV. Aynı Neviden Fikrî İçtima

Bir fiille aynı suç birden fazla kişiye karşı işlenmiş olabilir.

765 sayılı TCK'nın yürürlükte olduğu zaman zarfında bu konuda iki farklı görüş ortaya atılmıştı. Bunlardan birincisine göre, fiil sayısı *netice* ile belirlenmektedir. Örneğin bir hileli davranışla birden fazla kişinin aldatılması suretiyle haksız bir kazanç elde edilmesi halinde, birden fazla fiilin gerçekleştiği ve sonuçta birden fazla dolandırıcılık suçunun işlendiği kabul edilmekteydi. Ancak, bu durumda zincirleme (müteselsil) suç hükümlerinin (765 s. TCK, m. 80) uygulanması gerektiği ileri sürülmekteydi¹²⁷⁰. Yargıtay, bazı kararlarında bu görüşü benimsemişti¹²⁷¹.

Seçimlik hareketli suçlar, suçun kanuni tanımında gösterilen alternatifli hareketlerden herhangi birisinin işlenmesi ile tamamlanabilen suçlardır. Alternatifli hareketlerin hepsinin işlenmesi şart olmayıp, sadece bir tanesinin yapılması dahi suçun oluşması için yeterlidir. Alternatifli hareketlerden bir kaç ya da hepsi birlikte gerçekleştirilmiş olsa dahi ortada tek suç vardır. Bu nedenle seçimlik hareketli suçlarda hareketlerden bir kaçının veya tümünün yapılması, birden çok suça, dolayısıyla zincirleme suça vücut vermez. Dikkat etmek gerekir ki, seçimlik hareketli suçlarda suçun konusu değişmemektedir. Bu seçimlik hareketlerden her biri aynı konu üzerinde, aynı konu ile ilgili olarak gerçekleşebilmektedir. Bu itibarla seçimlik hareketli suçtan söz edebilmek için seçimlik hareketlerin aynı konuya ilişkin olması gerekir.

...

Sanığın hacizli olması nedeniyle gerçek plaka ve ruhsatı ile kullanamadığı aracını, başkası tarafından düzenlenen sahte plaka ve tescil belgeleri ile yakalandığı ana kadar kullandığı sabit olup, bu durumda resmi belgede sahtecilik suçu kanunda öngörülen seçimlik hareketlerden sahte belgenin kullanılması suretiyle işlenmiştir. **Aynı belgelerin süregelen kullanımı ise tek bir suçu oluşturmakta olup, işlenmiş birden çok suç bulunmadığından somut olayda zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartları bulunmamaktadır.**” CGK, 24.9.2013, E. 2012/11-1506, K. 2013/391.

Ayrıca işaret etmemiz gerekir ki, Yargıtay, resmi belgede sahtecilik suçu ile özel belgede sahtecilik suçunu “aynı suç” kabul ederek bu suçlar arasında da zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği yönünde içtihadta bulunmuştur:

“Sahtecilik suçları bakımından ise kanun koyucunun **resmi belgede sahtecilik** ve **özel belgede sahtecilik** suçlarını benzer şekilde düzenlemesi, her iki suçta korunan hukuki yararın kamu güveni olması, suçların mağdurunun geniş anlamda toplumu oluşturan tüm bireyler olması ve suç isimlerinin aynı olması nedeniyle, **resmi belgede sahtecilik suçu ile özel belgede sahtecilik suçunun “aynı suç” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.**” Bu nedenle sanığın ikisi özel belge, ikisi de resmi belge niteliğindeki toplam dört adet senedi sahte olarak düzenleyerek almış olduğu mal karşılığında mağdura verdiği somut olayda, mağdurun suça konu dört senedi sanıktan iki farklı zamanda aldığını açıkça ifade etmesi, sahte olarak düzenlenen senetlerdeki keşide ve vade tarihlerinin de bu anlatımı doğrulaması karşısında, sanık hakkında ... **zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.**” CGK, 19.11.2013, E. 2012/11-1376, K. 2013/458.

¹²⁷⁰ Bu konuda İçel'in görüşü için bkz. İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, sh. 432, 448, 455.

¹²⁷¹ «Sanığın av tüfeği ile, toplu halde bulunan şahıslara karşı, onlardan bir kaçının bu atıştan yaralanabileceğini bilerek yaptığı bir el ateş etme fiili ile çeşitli kanun hükümlerinin ihlâl edildiği Yerel Mahkemece de kabul edildiğine göre; olayımızda halli gereken husus TCK'nın 79. maddesinde kullanılan “bir fiil” deyiminden neyin anlaşılması gerektiğini tespit etmektir. Fiil, dış âlemdeki değişiklik olduğuna göre; fiilin esas kısmını, netice oluşturur. Şu halde, fikrî içtimanın bulunabilmesi için, her şeyden önce bu neticenin tek olması gerekir. Bu nedenle, bakılacak husus, dış âlemdeki değişikliğin birden fazla olup olmadığıdır.

Olayımızda ise, *av tüfeğiyle yapılan atış tek olmakla birlikte*, değişiklik ve *netice iki tanedir*. Ortada “bir fiil” yoktur ve “*fikrî içtima*” söz konusu edilemez.»: CGK.; 18.10.1982, 4-296/365 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1102 vd.).

Ancak işaret edelim ki; Yargıtay, bazı kararlarında bu gibi durumlarda gerçek içtimanın uygulanması gerektiği fikrindedir:

«Otomobilini yanlış yere parkeden sanık, hakkında ceza tutanağı düzenleyen görevli polis memurlarına fazla para cezası verdiklerinden bahisle kızarak ceza makbuzunu yırtmış ve her iki mağdurun yüzüne atmıştır. Sanığın, TCY'nin 266/1. maddesi uyarınca iki kez cezalandırılmasına karar verilmiş ve bu karar Özel Dairece onanmıştır.

Özel Daire ile Yargıtay C. Başsavcılığı arasındaki uyumsuzluk, aynı anda ve aynı söz veya davranışlarla birden fazla memura sövülmesi halinde gerçek teselsül hükümlerinin mi, yoksa gerçek içtima kurallarının mı uygulanması gerekeceğidir.

Sövme ve hakaret suçları, insan şeref ve haysiyetinin korunması amacıyla kabul edilmiştir. Sövme, kişilerin onurunu ihlâl ettiği için aynı anda birden fazla kişiye karşı işlendiğinde, kanunî tipe uygun birden fazla sonuç ve sonuca bağlı olarak da birden fazla fiil mevcuttur.

Fiilin birden fazla olması halinde de, kural olarak birden fazla ihlâl, birden fazla hüküm ve birden fazla ceza ile her ihlâlin ayrı suç olması nedeniyle de birden çok suç söz konusudur.

Maddi olayda sanık, trafik suçu işlemesi nedeniyle hakkında ceza tutanağı düzenleyen ve resmi araçta bulunan her iki görevli polis memurunun yüzüne karşı yırttığı ceza makbuzunu atmış ve aynı anda her ikisini birden tahkir edici davranışta bulunmuştur. Mağdurlar sadece iki kişi olup, sanık her ikisinin de görevli olduğunu bilmekte ve her ikisini de küçük düşürme amacıyla hareket etmektedir. Mağdurlar, bir grup şeklinde hedef alınmamıştır. Sanık, tek bir fiile bağlı olarak mağdur sayısınca suç işlemiştir. *Olayda teselsül hükümlerinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır*. TCY'nin 80. maddesinin uygulanabilmesi için aynı suç işleme kararı altında yasanın aynı hükmünün kısa zaman aralıklarıyla birkaç defa ihlâli gerekir. Müteselsil suçun kabulü için fiiller, aynı suç işleme kararı altında işlenmelidir. 80. maddenin önceki metninde yer alan “kasdı cürmî” ibaresi, (söz konusu) hükmün, kastın esas alınmadığı kabahatlere de uygulanabilmesi için 4055 sayılı Yasa ile “*bir suç işleme kararı*” olarak değiştirilmiştir. Yasanın aynı hükmünü ihlâl eden birden çok fiilin bulunması halinde müteselsil suçun kabulü için fiiller, “*aynı suç işleme kararı*” altında işlenmelidir. Halbuki olayda, aynı suç işleme kararı altında yasanın aynı hükmünün, kısa zaman aralıklarıyla birkaç defa ihlali söz konusu değildir. Fiilin teselsülünden söz edilemeyeceği cihetle *tek bir fiile bağlı mağdur sayısınca suç* olmuştur.»: CGK, 26.11.1996, 4-192/250 (YKD, Şubat 1997, sh. 271 vd.).

«Olayımızda sanık haciz için gelen icra memuru ile alacaklı avukatına çoğul anlatımla “*siktir olun gidin*” demek suretiyle aynı anda hakaret etmiştir (doğru ifadeyle, sövmüştür). Mağdurların sayısı bir topluluk teşkil edecek derecede değildir. Mağdurlar bir grup şeklinde hedef alınmış da değildir. Sadece iki kişi olup, haciz işlemi için eve geldikleri sanık tarafından bilinen görevlilerdir. Sanık her ikisini ayrı ayrı tahkire yönelip, belirtilen sözlerle her ikisine de hakaret etmiştir. Bu itibarla, olayda tek sövme suçu değil, mağdur sayısınca suç oluşmuştur.

Ancak, teselsül hükümlerinin uygulanabilmesi için aynı suç işleme kararı altında yasanın aynı hükmünün birkaç defa ihlâli gerekir. Olayımızda ise, tek tek ve ayrı ayrı mağdurların hedeflendiği anlaşıldığından, karar birliğinden ve bunun sonucu olarak teselsülden söz edilemez. Tek bir fiille mağdur sayısınca suç işleme hali saptanmıştır.

Şu halde, sanık hakkında TCK'nın 71. maddesi yerine 80. maddesiyle uygulama yapılmasında isabet bulunmamaktadır.»: CGK, 14.5.1996, 4-92/95 (Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 1206).

«Sanık, saçmaların dağılması tabii ve muhakkak olan av tüfeğiyle gerideki kalabalığa ateş ederek üç kişiyi yaraladı (dığına göre); *her yaralama bir suç sayılmak icap ederken*, 79. maddeden bahisle bir ceza tayini yolsuz»dur 2. CD, 5.12.1962, 12579/14339 (Savaş/Mollamahmut-oğlu I, sh. 1114).

F, “aynı anda ve tek bir cümle ile iki astsubaya birden hakarete bulunmuş(tur). Bu gibi hallerde muhtelif suçlar şahsa sıkı surette bağlı olan ve kolektif şekilde ortaya çıkmalarına imkân bulunma-

Buna karşılık, gerçekleşen fiil ve suç sayısını *harekete* göre belirleyen anlayış ise, yukarıdaki örnek olayda bir hareketin gerçekleştiğini kabul etmekteydi. Ancak, bu bir hareketle kanunun “muhtelif ahkâmı”nın ihlâl edildiği ve (farklı neviden) fikrî içtima hükümlerinin (765 s. TCK, m. 79) uygulanması gerektiği ileri sürülmekteydi. Yargıtay da bazı kararında bu görüşü benimsemişti¹²⁷².

yan hakları ihlâl etmekte ise; kaç şahsın hakkı ihlâl edilmişse o kadar suç vardır ve binnetice mağdurların çokluğu, bu nevi suçlarda müteselsil suçun mevcudiyetini imkânsız kılar. ... Hakaret ve sövme suçlarının cezalandırılmasında güdülen amaç, insan şeref ve haysiyetinin korunması olduğundan; isterse bir yerde, bir zamanda harcanan tek bir sözlü hakaret ve sövme yapılmış olsun; *burada kaç kişinin şeref ve haysiyeti zedelenmiş ise, o kadar sayıda suç işlenmiş sayılır.*” Ask. Yarg., 5. D, 20.6.1990, 337/333 (Ask. Yarg. KD., 9[1992], sh.11).

«... (B)irden çok görevliye sövdüğü halde, suçun mağdur sayısının oluşacağı gözetilmeden ve içtima biçimi tartışmadan; tek hüküm verilmesi,» doğru değildir. 4. CD., 28.2.1996, 514/1712 (YKD, Ağustos 1996, sh. 1315 vd.).

¹²⁷² «6.4.1986 günü, Sivas Stadyumunda Vanspor - Sivasspor Kulüpleri arasında yapılan futbol maçı dolayısıyla, 10 jandarma eri kale arkasında görevlendirilmiştir.

Maç sonuna doğru kale arkasında çıkan olaylar sırasında, Sivasspor yöneticilerinden M, tecavüze uğrayanları korumaya ve olayın büyümesini önlemeye çalışan jandarma erlerinin tümünü kasederek, “a... *koyduğumun askerleri; siz de mi Vanspor’u tutuyorsunuz?*” şeklinde sözler (sarfetmiştir).

Özel Daire ile, Yerel Mahkeme arasında(ki) uyuşmazlık konusu; M’nin fiilinin tek suç mu, (yoksa mağdur sayısınınca birbirinden) ayrı suç(lar) mı teşkil edeceği hususudur.

Konunun Genel kurulumuzda müzakeresi sırasında ortaya atılan ve çoğunluk görüşüne esas alınan bilimsel görüşler ve mahkeme içtihatları aşağıda özetlenmiştir.

a) Aynı söz ve hareketlerle birden fazla memura karşı vuku bulan tahkir fiilinin tek suç mu, yoksa memur sayısınınca suç mu sayılacağı konusunda öğreti ve uygulamada tartışma mevcuttur.

Bir görüşe göre, aynı zamanda ve aynı sözle iki veya daha fazla memura karşı hakaret ve sövme suçunun işlenmesi halinde, tahkire maruz kalan memurların sayısınınca suç değil, tek suç teşekkül eder. İtalyan müelliflerinden bir kısmı da tek suçun teşekkül ettiğini ileri sürmekle beraber, bunların hareket noktaları değişiktir. Bu müelliflere göre memura karşı hakaret ve sövme suçlarından tahkire maruz kalan memurlar birden fazla olsa bile, bu suçlarda mağdur TEKTİR ve o da, Devlet idaresidir. Kanun koyucunun gayesi, memurun kişisel şeref ve haysiyetinden ziyade, devlet faaliyetinin himayesidir. Bu itibarla aynı söz ve hareketlerle birden fazla memur tahkir edilse dahi tek suç vardır.

Başka bir görüşe göre de, aynı söz ve hareketle birden fazla memura yönelik tahkirlerde, tahkire maruz kalan memur sayısınınca suç teşekkül eder ve fail her bir tahkir suçundan ayrı ayrı sorumlu olur.

Genel tahkir suçlarında kabul edilen ve bizim de memura karşı tahkir suçlarında geçerli olabileceğine inandığımız görüşe göre, burada failin kastını araştırmak gerekir; şayet, fail, müteaddit memurlardan her birini ayrı ayrı tahkir etmek gayesiyle hareket etmiş veya her birini ayrı ayrı hedef almış ise tek suç değil, memur sayısınınca suç vardır. Şayet, fail, her bir memura karşı ayrı ayrı değil de, hareketi yönettiği memurları bir topluluk, gurup şeklinde hedef almışsa TEK SUÇ vardır. Bu itibarla, suçun mağduru Devlet idaresi olduğundan, hangi sayıda memur tahkire maruz kalırsa kalsın tek suç vardır diyen görüşe katılamıyoruz. Çünkü, tahkire maruz kalan her bir memur dolayısıyla Devlet faaliyeti sekteye uğratılma tehlikesiyle karşılaşacaktır.

b) Şayet mağdurların adedi bir “topluluk” teşkil edecek derecede olup, fail de bu topluluğun heyeti mecmuasına tahkir etmişse, topluluğa karşı hakaret veya sövme suçu teşekkül eder ve ortada TEK SUÇ bulunur. Topluluğa mensup olan şahıslar, yeter derecede tayin ve teşhis edilmişlerse, fail

aleyhine takibatta bulunabilirlerse de, bu keyfiyet suç ve cezanın taaddüdünü mucip olmaz ve müteaddit dava haklarının sureti istimali CMUK'un 345. maddesine göre tanzim edilir.

Buna mukabil, mağdurlar bir “topluluk” teşkil etmedikleri gibi, fail de her birinin şerefini ayrı ayrı ihlal eylemek istemişse, ihlal ettiği hukuki menfaatler adedince suç işlemiş olur ve hakiki içtima kaidelerinin tatbiki iktiza eder. Müteaddit eşhası tahkir etmek isteyen kimsenin, müteaddit zamanlarda ve aynı zamanda ika etmesi ve mezkur elfazı bir defada söylemesi arasında hukuken hiçbir fark gözetilemez.

c) Mağdurun birden ziyade oluşu her zaman mağdur adedince suça vücut vermez. Eğer isnat aynı fiile taalluk ediyorsa, mağdurun adedine bakılmamalıdır. Veren ve alan ismen gösterilmek suretiyle rüşvet isnadında bulunmak; bir kadına, erkek ismi açıklamak suretiyle zina isnat etmek hallerinde iki değil, TEK SUÇ mevcut olmalıdır.

d) Ceza Genel Kurulunun 5.5.1941 gün ve 33/30; 4. Ceza Dairesinin 31.5.1946 gün ve 6382/7081, 30.1.1951 gün ve 9150/1050, 30.11.1951 gün ve 9150/9150, 14.12.1951 gün ve 9655/6565, 30.12.1955 gün ve 20332/20796, 24.1.1956 gün ve 15968/639; Askeri Yargıtay 3. Dairesinin 23.5.1967 gün ve 228/231 sayılı kararlarında, aynı zamanda ve aynı sözle iki veya daha fazla memura hakaret TEK SUÇ; 4. Ceza Dairesinin 23.3.1966 gün ve 969/1261 sayılı kararında, topluluğa karşı hakaret TEK SUÇ kabul edilmiştir.

Yukarıda açıklanan bilimsel görüşler ve Yargıtay kararları birlikte değerlendirildiğinde; Si-vasspor-Vanspor maçında çıkan olaylarda, tecavüze uğrayanları korumaya ve olayın büyümesini önlemeye çalışan ve bir “topluluk” teşkil eden *jandarma erlerinin tümünü hedef alarak suç konusu hakaretimiz sözleri söyleyen sanığın eyleminin TEK SUÇ sayılmasında zorunluluk bulun*maktadır.

Karşıoy yazısı (*Sami Selçuk*):

«Sanığın eylemi görevleri nedeniyle birden çok jandarma erinin yüzüne karşı çoğul bir anlatım kullanarak sövmekten ibarettir.

Yüksek Daire ve sayın çoğunluk, bu eylemi, görüşmeler sırasında da açıklanan düşüncelere göre; hukuksal konu, eylemin bir topluluğu amaçlaması ve cürüm kastı temellerine dayandırmış ve tek olarak benimsenmiştir. Aşağıdaki nedenlere bu görüşü paylaşmakta olanaksızdır.

Her şeyden önce, *bir eylemin tekliği ve çokluğu*, Türk Ceza Yasasının sisteminde, kaynak yasanın gerekçesinde de belirtildiği gibi, *eylemin doğurduğu maddi sonuç sayısına göre belirlenir*. Eğer suç sövme gibi, maddi sonucu olmayan salt hareket suçu ise, adil sonucu varmak için bu kuraldan ayrılmak ve ihlal edilen konu (menfaat, varlık, değer) sayısına bakmak gerekir. Tek sözle birden çok kişiye sövmeye kişi sayısınca onurun, bireysel değer (varlığın ya da menfaatin) ihlal edildiği tartışma götürmez bir gerçektir. O yüzden de *kişi sayısınca suç* ortaya çıkacaktır. Yargıtay’ımızın yerleşmiş görüşü de yerinde olarak böyledir.

Öte yandan, her ne kadar Türk Ceza Yasasının 266. maddesi, sistematik çatı içinde, devlet yönetimine karşı cürümler arasında yer almışsa da, bu suçun iki hukuksal konusu vardır: a-Devlet yönetimi, b- kişilerin onuru. Çünkü suçun hukuksal konusunu yalnızca sistematik çatı belirlemez. Onun yanı sıra, suçun özyapısı da belirler. Yasa koyucu, birden çok değeri, varlığı ya da menfaati koruyan suçlarda, suçu aynı Yasanın birçok yerinde düzenleyemeyeceği için, tek bir kesimde düzenlemek, bu konulardan birini (öne) çekmek zorundadır. Ancak, bu zorunluluk, öbür hukuksal konunun bütünüyle gözden çıkarıldığı anlamına gelemmez. Yorumcu ve uygulayıcı, onu gözetmek zorundadır. İnceleme konusu hükümde de durum aynıdır. Yasa koyucu, izlediği suç ve ceza politikasına göre seçimini yapmış, görevli kişilere sövme suçunu, devlet yönetimine karşı cürümler arasında düzenlemek gereğini ve zorunluluğunu duymuştur. İki konu ihlal edildiği için de görevli olmayan kişilere karşı işlenen cürümlere oranla daha ağır bir yaptırım uygulamasını öngörmüştür. Bu nedenlerle, yalnızca devlet yönetimini gözeterek, görevli mağdurların bu hükümle korunan onurlarını gözardı eden çoğunluk görüşüne katılmak olanaksızdır.

İkinci olarak, çoğunluk görüşünün bu çıkış noktasının doğurduğu determinist sonuçlar, yasayla ve Yargıtay’ın görüşleriyle de çatışmaktadır.

Gerçekten, iftira cürmünde de durum aynıdır. İftira suçu, yasal sistematiğe adalet yönetimine karşı cürümler arasında yer almaktadır. Ancak bu suçla da iki ayrı hukuksal konu korunmaktadır. a- Adalet yönetimi, b- Kişilerin onuru. İftira suçu işlendiğinde iki konu birden ihlal edilmiş olmaktadır. O yüzde Yargıtay, haklı olarak, *birden çok kişiye tek eylemle iftira cürmünde, kişi sayısınca suçun işlendiğini* benimsemiştir.

Bundan başka, Yargıtay'ın, yukarıda da belirtildiği gibi, görevsiz kişilere karşı tek sözcükle sövmeyi, mağdur sayısınca suç olarak benimsemiş; yasa ile, görevli kişilere karşı sövmeyi daha ağır yaptırımlarla cezalandırmıştır. Çoğunluk görüşü paylaşılar, görevli kişilere karşı tek sözle sövme tek suç olarak benimsenirken, ortaya şöyle bir sonuç çıkacaktır:

Fail, görevsiz kişilere karşı suç işlerse kişi sayısınca eylemden dolayı daha çok cezalandırılacaktır ve birden çok hükümden dolayı hükümlü olacaktır. Buna karşılık görevli kişilere karşı suç işlediği takdirde, ödüllendirilmiş olacak ve dolayısıyla tek suçtan sorumlu tutulacak ve tek suçtan hükümlü olacaktır. Nitekim, olayımızda öyle olmuştur. Oysa yasa, görevliye karşı işlenen cürmü daha ağır yaptırıma bağlamıştır. Bir başka deyişle, bu anlayışa göre, ağırlaştırıcı neden, fail için bir tür hafifletirici nedene dönüşmüş ve bu yolda rol oynamış; bu yüzden de Ceza Yasasının özüne ters düşünülmüştür. Çoğunluk görüşünün gerekçesinin determinist, kaçınılmaz bir sonucu olan bu paradoksal durumu açıklamak olanaksızdır.

Dahası, çoğunluk görüşüne göre, Türk Ceza Yasasının 266. maddesindeki suç, yalnızca Devlet yönetimini ihlal ettiği, kişilerin onurunu ihlal etmediği için, Türk Ceza Yasasının 38. maddesine göre mağdurların manevi ödence istemleri de olanaksızdır. Çoğunluk görüşünün zorunlu olarak ulaştığı ve yasaya ve yerleşmiş yargısal görüşlere uymayan sonuçlarından biri de budur.

Çoğunluk görüşünün görüşmeler sırasında ileri sürdüğü dayanaklardan biri de şudur: Fail, jandarma topluluğuna sövmüştür. O yüzden eylem tektir. Oysa Türk Ceza Yasasında topluluklara, kurullara sövme suçları (md. 268, 493) uyarınca ve sınırlı olarak düzenlenmiştir. Olayımızda, bu maddelerdeki gibi, bir topluluk, kurul değil, olay yerinde görevlendirilmiş birkaç mağdur vardır. Kavram yanılığı, yorum yanılığına dönüşmüştür.

Yine görüşmeler sırasında, çoğunluk görüşü, önceki paragrafta sözü edilen jandarma topluluğu kavramından yola çıkarak failin bu topluluğa karşı suç işleme kastıyla hareket ettiğini ileri sürmüştür. Bu görüşü de paylaşmak olanaksızdır. Önce, suç kastıyla failin amacı birbirine karıştırılmıştır. Amaç; kastın tersine, hukuksal bir kavram değildir. *Kast ise, bir eylemi bilinçle ve iradeyle işlemektir.* Olayımızda fail, birden çok ve görevli kişilere sövme bilinciyle ve kendisini kimse zorlamadığı için de, bu iradeyle sövmüştür. Kullandığı çoğul anlatım bunu doğrulamaktadır. Fail, hem jandarmaların onurunu ve Devlet yönetimini ihlal ettiğini bilmektedir ve hem de irade etmektedir. Öyleyse, suç kastından yola çıkıldığında da, birden çok kişinin onurunu ihlal bu kastın içinde olduğu için, *fail, kişi sayısınca suç işlemiş olmaktadır.* Eğer fail, sövdüğü mağdurların görevli jandarma olduklarını, yani niteliklerini bilmeseydi, ağırlaştırıcı neden yanlığı yüzünden suç kastının dışında kalacak ve fail Türk Ceza Yasasının 482. maddesi uyarınca ve mağdur sayısınca suç işlediği gerekçesiyle cezalandırılacaktı. Elbette Türk Ceza Yasasının 268. ve 483. maddelerine göre cezalandırılmayacaktı. Görülüyor ki; *kasten tek tek jandarmalara değil, tersine jandarma topluluğuna yöneldiği ve bu yüzden de tek kast ve tek suç olduğu görüşü de, somut gerçekle bağdaşmayan yapay ve ütöpik bir soyutlamadır.*

Yüce Kurulda, mağdur sayısının 50, 100, 1000 gibi büyük rakamlara ulaştığında durumun ne olacağı, abartılmış sorularla sorularak, konuya yaklaşılmaması ise, bizce yerinde değildir ve yorum kurallarını aykırıdır. Hukukta, yorum, insanları kurtarmak için değil, doğruyu bulmak ve tek uygulamayı sağlamak için yapılır. *Suç failleri de, işledikleri suç sayısınca, yani kaç kişiye sövdüklerini biliyorlarsa, o kadar suça göre cezalandırılırlar, düşsel varsayımlara göre değil.»* CGK, 4.5.1987, 9-127/253 (Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 1231 vd.; Uygun/Savaş/Mollamahmutoğlu, CGK. Kararları 1987, sh. 68 vd.).

Kanımızca, bu gibi olaylarda zincirleme (müteselsil) suç hali söz konusu değildir. Çünkü, aynı suç birden fazla işlenmiş değildir. Keza, bu olaylarda farklı neviden fıkri içtima hükümleri de uygulanamaz. Çünkü, bir fiil ile birden fazla farklı suçun işlenmesi hali söz konusu değildir¹²⁷³.

Nitekim, yeni TCK'da gerçekleşen suç sayısı belirlenirken netice değil, fiil esas alınmıştır. Ancak, **bir fiille aynı suç birden fazla kişiye karşı** işlenmiş olabilir. Bu durumda, **aynı neviden fıkri içtima** söz konusudur (m. 43, f. 2)¹²⁷⁴.

Bir fiille birden fazla kişiye karşı hakaret edilmesi (m. 125), bir şikâyet dilekçesi ile birden fazla kişiye karşı iftirada bulunulması (m. 267), bir fiille birden fazla kişiye karşı cinsel tacizde bulunulması (m. 105), bir fiille birden fazla kişinin tehdit edilmesi (m. 106), bir fiille birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (m. 109), bu içtima şekline ilişkin örnekleri oluşturmaktadır¹²⁷⁵.

¹²⁷³ ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku, 2. bası, İstanbul 1998, sh. 182.

¹²⁷⁴ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 653. Aynı neviden fıkri içtima hakkında açıklamalar için bkz. GÖKTÜRK, Fıkri İçtima, sh. 183 vd.; CGK, 2.3.2010, E. 2009/9-259, K. 2010/47.

¹²⁷⁵ Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 7.6.2012 tarihli ve E. 2011/17791, K. 2012/6524 sayılı Kararına konu teşkil eden olay şu şekilde cereyan eder:

Saadet ile Ramazan boşanırlar. Bu evlilikten Enes ve İlayda adlarıyla iki çocukları bulunmaktadır.

Boşanmadan önce Saadet, eşi Ramazan ve çocukları, eşinin babası ve kardeşi Emin ile birlikte aynı evde otururlar.

Boşanmadan sonra Saadet, babasının evine taşınır.

Boşanmaya varan uyuşmazlıklar sebebiyle Ramazan, Saadet'in babası Uzeyir tarafından öldürülür.

Saadet, Ramazan'ın öldürülmesinden sonra, velayeti kendi uhdesinde bulunan çocuklarının birlikte kaldıkları amcaları Emin'den kendisine teslim edilmesini ister.

Ancak Emin, ağabeyi Ramazan Saadet'in babası tarafından öldürüldüğü için, henüz 12 yaşını tamamlamamış olan çocukları Saadet'e teslim etmez.

Esas mahkemesi bu olayda,

a) Emin'in fiilinin TCK'nın "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" başlıklı 234. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçu oluşturduğunun kabulüyle hakkında cezaya hükmetmiş,

b) kaçırılan her iki çocuğun henüz on iki yaşını bitirmemiş olması sebebiyle, söz konusu maddenin birinci fıkrasına göre belirlediği cezayı ikinci fıkrası hükmüne istinaden artırmıştır.

Mahkeme, sonuç ceza olarak altı ay hapis cezasına mahkum ettiği Emin hakkında, kişilik özelliklerini dikkate alarak, bu hapis cezası yerine TCK'nın 50. maddesinde belirlenen seçenek yaptırımlardan birine hükmetmemiştir. Keza, söz konusu hapis cezası, TCK'nın 51. maddesi hükümlerine istinaden Mahkemeye ertelenmemiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, söz konusu olayda, "**alıkonulan çocuk sayısı kadar suçun oluşacağı gözetilmeden tek suçtan hüküm kurulması**"nı hukuka aykırı bulmuştur.

Esas Mahkemesi, alıkonulan çocuk sayısının birden fazla olmasını mahkumiyet hükmünün te-sisinde dikkate almamıştır.

14. CD ise, mahkumiyet hükmündeki bu eksikliği, bozmayı gerektiren bir hukuka aykırılık olarak değerlendirmiştir.

14. CD'nin bu içtihadı, çocuğu (TCK, m. 234, f. 1'de tanımlanan) söz konusu suçun mağduru olarak kabul etmesi itibarıyla doğrudur. Alıkonulan çocuk sayısı iki olduğuna göre, bu suçun

Aynı neviden fikrî içtima halinde, **bir fiil** vardır ve bu fiil ile aynı suç birden fazla kişiye karşı işlenmiş olmaktadır. Bir fiil ile aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlenmiş olmasına rağmen, fail hakkında kural olarak mağdur sayısınınca cezaya değil, **bir cezaya** hükmolunur. Fakat, bu **ceza artırılır** (m. 43, f. 1, 2). Aynı neviden fikrî içtima dolayısıyla cezada yapılacak olan artırma oranıyla ilgili olarak zincirleme suç hükmüne atıfta bulunulmuştur.

Zincirleme suç ile aynı neviden fikrî içtima arasındaki tek müştereklik, cezada yapılabilecek artırıma ilişkin oranların aynı olmasından ibarettir. Aslında birbirlerinden farklı durumlara ilişkin iki ayrı içtima hükmünün ayrı maddelerde düzenlenmesi daha yerinde olurdu. Ancak, yeni TCK'ya ilişkin olarak TBMM Adalet Komisyonundaki çalışmalarımız sırasında bunu izahta karşılaştığımız güçlük nedeniyle, her iki içtima durumunu aynı madde altında düzenlemek mecburiyetinde kalmış bulunmaktayız.

Yeni TCK'nın 43. maddesinin ikinci fıkrası bağlamında şu iki hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

Birinci husus, örneğin birden fazla kişinin iştirak halinde veya müşterek malik olarak maliki olduğu bir otomobilin çalınması halinde, bir hırsızlık suçu işlenmiş kabul edilecektir. Çünkü, suçun konusu aynıdır. Aynı olan suçun konusu üzerinde birden fazla kişinin iştirak halinde veya müştereken malik olması bu eşyaya yönelik olarak hırsızlık suçunun işlenmesi halinde, mağdur sayısınınca suçun oluştuğunu söylemek mümkün değildir. Bu durumda fiilin tekliğinin yanı sıra, suçun konusu da tektir. **TCK'nın 43. maddesinin ikinci fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için, suçun konusunun da farklı olması** gerekir.

İkinci husus, failin hırsızlık suçunun konusunu oluşturan her bir eşyanın mülkiyetinin farklı kişilere ait olmasına rağmen, bu eşya üzerinde bir kişi zilyed olabilir. Mülkiyeti farklı kişilere ait olan eşya üzerinde emanetçi konumunda bir kişi zilyeddir. Emanetçi ambarında bulunan mülkiyeti farklı kişilere ait eşyaların çalınması halinde, suçun mağduru, bu eşyalar üzerinde meşru zilyed konumundaki emanetçidir. Farklı kişilere ait olan eşyayı nakletmekte olan bir kamyoncu, bu

işlenmesiyle **her iki çocuğun mağdur edildiğinin** kabulü doğrudur. Bu iki çocuğun yanı sıra, velayet kendi uhdesinde bulunan anne Saadet'in de mağdur edildiği kabul edilebilir.

Ancak, 14.CD'nin söz konusu içtihadında, fiil sayısının, alıkonulan çocuk sayısı dikkate alınarak belirleneceği kabul edilmiştir. Başka bir ifadeyle, 14.CD bu olayda **gerçek içtima** hükümleri uygulanarak, **mağdur sayısınınca alıkoyma suçunun** işlendiğinin kabulüyle, her bir mağdur itibarıyla 234. madde hükümlerine göre ayrı ayrı cezaya hükmedilmesi ve bu cezaların toplanması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

Bu yöndeki kabulün doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bu olayda **ihmali davranışla işlenmiş bir suç** vardır. Teslim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi şeklindeki **bir ihmali hareketle birden fazla kişinin mağduriyetine sebebiyet verilmiştir**. Bu nedenle, söz konusu olayda **aynı neviden fikrî içtima** hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, bu olayda 234. maddenin birinci fıkrasına istinaden belirlenen ve ikinci fıkrası hükmüne istinaden artırılan ceza, ayrıca TCK'nın 43. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne istinaden artırılmalıdır.

eşya üzerinde meşru zilyedir. Kamyondan bu eşyaların çalınması halinde, mağdur, zilyed konumundaki kamyon şoförüdür. Bu itibarla, söz konusu örnek olaylarda **bir hırsızlık suçunun** işlendiğini kabul etmek gerekir. Bu örnek olaylarda suçun konusunu oluşturan muhtelif eşyanın mülkiyeti farklı kişilere ait olsa bile, bu eşya üzerindeki hakimiyeti ve zilyetliği esas alarak, bir hırsızlığın işlendiğini kabul etmek gerekir. Muhtelif kişiler tarafından vestiyer görevlisine teslim edilmiş olan palto gibi eşyanın çalınması halinde, bir hırsızlık suçu işlenmiştir. Bu durumlarda her bir malik suçtan zarar gören olmakla birlikte, suçun mağduru, eşyanın emanet edildiği, zilyetliğinin devredildiği şahıstır.

Keza, bir bankadaki farklı kişilere ait hesaplardan para çekmek suretiyle işlenen hırsızlık suçunda, hesap sahibi kişi sayısınca hırsızlık suçunun oluştuğunu kabul etmek mümkün değildir. Bu durumda, hırsızlık suçunun mağduru, bankanın ortağı ve müşterek maliki konumundaki gerçek kişilerdir. Şayet, birden fazla hesaptan aynı anda para çekilmişse, olayda bir hırsızlık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Bankadaki çeşitli hesaplardan farklı zamanlarda para çekilmek suretiyle hırsızlık suçunun işlenmesi halinde, birden fazla hırsızlık suçunun oluştuğunu ve fakat, aralarındaki psikik bağ dolayısıyla zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğini kabul etmek gerekir.

Buna karşılık, eşya, üzerindeki hakimiyet bir başkasına tevdi edilmeden, mülkiyet veya zilyetlik devri olmaksızın, korumasız bir şekilde, hırsızlığa karşı herhangi bir tedbir alınmaksızın bir yerde bırakılmış olabilir. Örneğin yaygın uygulama olarak camilerde ibadet sırasında, kişiler ayakkabılarını herhangi bir koruma olmadan ayakkabılığa bırakırlar. Bu durumda olan eşya çalındığı takdirde, bunların mülkiyeti farklı kişilere ait olduğu için, farklı kişiler mağdur edilmiştir. Ancak, bu durumda hukuki anlamda fiil tekliğini kabul ederek, **aynı neviden fikri ictima** hükümlerini uygulamak gerekir. Yani bu durumlarda bir fiil ile birden fazla kişiye karşı işlenmiş hırsızlık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Bu itibarla, söz konusu durumlarda, çalınan eşyanın mülkiyetinin farklı kişilere ait olduğu göz önünde bulundurularak, eşyası çalınan kişi sayısınca hırsızlık suçunun işlendiği sonucuna varılamamalıdır^{1276, 1277, 1278}.

¹²⁷⁶ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun 22.4.2014 tarihli ve E. 2013/13-5, K. 2014/204 sayılı kararına konu teşkil eden olayda S, cuma namazı vaktinde, içeride kimsenin bulunmadığını düşündüğü öğretmenler odasına girer. Odada biri masanın üzerinde diğeri kapısı açık dolapta bulunan iki adet dizüstü bilgisayar ile kapısı açık başka bir dolapta bulunan bir cep telefonunu alır.

Bu olayda bilgisayarlar ve mobil telefon cihazı farklı öğretmenlere aittir. Ceza Genel Kurulu, bu sebeple olayda “tek bir fiilden bahsedilemeyeceği, kaldı ki fiilin gerçekleştiriliş şekli itibarıyla hukuki anlamda tek fiilin söz konusu olmadığı, bu durum karşısında tek bir hırsızlık suçunun oluşmasının söz konusu bulunmadığı gibi, zincirleme suç hükümlerinin de uygulanmasının mümkün olamayacağı” düşüncesiyle, esas mahkemesi tarafından S “hakkında üç mağdura karşı işlenen hırsızlık suçundan ayrı ayrı mahkûmiyet hükmü kurulmasında bir isabetsizlik” görmemiştir. Bu nedenle Ceza Genel Kurulu, 13. Ceza Dairesi'nin S hakkında bir hırsız-

Geceleyin bir konuta girmek suretiyle işlenen hırsızlık suçunda suçun konusunu oluşturan eşyalardan bir kısmının bayan ziynet eşyası, bir kısmının ise, ceket cebinden alınan cüzdan ile içindeki para ve çeklerden ibaret olması halinde; suçun konusunu oluşturan ziynet eşyalarının bir hanımefendiye, cüzdan ile içindeki para ve çeklerin ise bir beyefendiye ait olduğu ve dolayısıyla, birden fazla kişiye karşı hırsızlık suçunun işlendiği düşünülebilir. Ancak, bu gibi durumlarda, **bir hırsızlık suçunun** işlendiğinin kabulü gerekir; TCK'nın 43. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerinin uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadır.

Bu açıklamalarımızdan çıkan sonuç şudur: Bir konuta girerek işlenen hırsızlık suçu örneğinde, eşyaların sahibi olan kişiler, aynı konutu müştereken kullanmaktadırlar. Her ne kadar eşyaların mülkiyeti farklı kişilere ait ise de, aynı konutu paylaşan kişilerin eşyası birbirlerinin müşterek güvenine tevdi edilmiş olduğu için, olayda **bir hırsızlık suçunun** işlendiğini kabul etmek gerekir. Başka bir deyişle, bu gibi durumlarda, birden fazla kişinin mağdur edildiği düşünce-sinden hareketle, mağdur sayısınca suçun oluştuğunu ve dolayısıyla, gerçek iç-tima hükümlerinin uygulanması gerektiği sonucuna varılamaz ve keza; bir fiille

İlk suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması gerektiği yönündeki içtihadını doğru bulmamıştır (Ayrıca bkz. CGK, **15.4.2014**, E. 2013/13-282, K. 2014/192).

Yukarıda açıkladığımız düşüncelerle, Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu içtihadına katılmamaktayız.

¹²⁷⁷ Yargıtay 2.CD'nin **22.12.2014** tarihli ve E. 2013/35419, K. 2014/30823 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda çocuklar A ve B, kilitlenmeden sokağa park edilen aracın içinde bırakılan MA ile ÇB'ye ait cep telefonları ile ÇB'ye ait içinde 126 TL para bulunan çantayı çalarlar.

Esas Mahkemesi, bu olayda failleri hırsızlık suçundan mahkûm ederken, zincirleme suç hükümlerini de uygulamıştır.

Daire bu olayda çocukların sorumluluğunun, çaldıkları eşyanın farklı kişilere ait olduğunu "bilebilecek durumda" bulunup bulunmamlarına göre tayin edilmesi gerektiği yönünde içtihadta bulunmuştur. Buna göre, şayet çocuklar çaldıkları eşyanın farklı kişilere ait olduğunu "bilebilecek durumda" iseler, mağdur sayısınca hırsızlık suçu oluşacaktır. Aksi takdirde, fiil "tek bir hırsızlık suçunu" oluşturacaktır ve TCK'nın 43. maddesinin ikinci fıkrası hükümleri, failler hakkında uygulanamayacaktır.

Bu içtihadı iştirak etmeyeceğimiz, izahtan varestedir.

¹²⁷⁸ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu'nun 6.6.2017** tarihli ve E. 2017/13-566, K. 2017/317 sayılı kararına konu teşkil eden olayda S, şikâyetçilerin ikamet ettiği binaya hırsızlık amacıyla gelecek binanın bodrum katında bir arada bulunan, üzerlerinde farklı seri numaraları yazılı şikâyetçilere ait on ayrı su sayacını çalar.

Ceza Genel Kurulu, aşağıdaki gerekçe ile bu olayda sayaç sahibi kişi sayısınca hırsızlık suçunun oluştuğu ve S hakkında gerçek içtima hükümlerine istinaden cezaya hükmedilmesi gerektiği yönünde içtihadta bulunmuştur.

"on ayrı daireye ait su sayacının ayrı ayrı çalınması nedeniyle doğal anlamda tek bir fiilden bahsedilemeyeceği, kaldı ki eylemin gerçekleştiriliş şekli itibarıyla hukuki anlamda tek bir fiilin de söz konusu olmadığı, bu durumda sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, yerel mahkemece sanık hakkında her bir şikâyetçiye yönelik hırsızlık suçu nedeniyle ayrı ayrı mahkûmiyet hükmü kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığı kabul edilmelidir"

aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlendiği düşüncesiyle TCK'nın 43. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri gereğince hırsızlık suçundan dolayı verilmesi gereken cezanın artırılması yoluna gidilemez¹²⁷⁹.

Yeni TCK'nın 43. maddesinin üçüncü fıkrasında, aynı neviden fikrî içtima açısından da geçerli istisna hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, bir fiille birden fazla kişiye karşı işlenmiş olan **kasten öldürme** veya **kasten yaralama** suçlarında, ölen veya yaralanan kişi sayısınca ayrı ayrı cezaya hükmolunacaktır. Keza, bir tehdit ile birden fazla kişi korkutulmak suretiyle haksız bir kazanç elde edilmesi durumunda da, mağdur sayısınca **yağma** suçunun oluştuğu kabul edilmektedir¹²⁸⁰. Aynı şekilde, kişiden kendisine isnat edilen bir suçla ilgili ola-

¹²⁷⁹ Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin 3.12.2014 tarihli ve E. 2014/28392, K. 2014/28891 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, F, hırsızlık amacıyla üniversite öğrencilerinin birlikte kaldığı eve girer; öğrenci MA'ya ait bir adet dizüstü bilgisayar, E'ye ait iki adet cep telefonunu, bir adet MP4 playeri, bir adet flash belleği alıp götürür.

Esas Mahkemesi bu olayda, F hakkında hırsızlık suçundan dolayı mahkumiyet hükmü kurar ve cezaı zincirleme suç hükümlerine göre artırır.

Daire bu olayda F'nin sorumluluğunun, çaldığı eşyanın farklı kişilere ait olduğunu bilip bilmemesine göre tayin edilmesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur. Buna göre, şayet F, çaldığı eşyanın farklı kişilere ait olduğunu biliyor ise, mağdur sayısınca hırsızlık suçu oluşacaktır. Farklı mağdurlara ait olduğu anlaşılan eşyaların çalınması halinde, aynı mekânda bulunsalar bile, tek bir hırsızlık suçu değil, mağdur sayısınca hırsızlık suçu oluşur ve fail hakkında "zincirleme suç" (doğrusu, aynı neviden fikrî içtima) hükümleri uygulanamaz. Aksi takdirde, yani F, çaldığı eşyanın farklı kişilere ait olduğunu bilmiyor ise, fiil "tek bir hırsızlık suçunu" oluşturacaktır ve TCK'nın 43. maddesinin ikinci fıkrası hükümleri, failer hakkında uygulanamayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımız itibarıyla, Karara konu teşkil eden olayla ilgili olarak Esas Mahkemesi ve Daire Kararlarında benimsenen görüşlere iştirak etmiyoruz. Ayrıca belirtmek gerekir ki, söz konusu Daire Kararında konut dokunulmazlığının ihlali suçuna ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer verilmez.

¹²⁸⁰ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 7.2.2012 tarihli ve E. 2011/6-332, K. 2012/21 sayılı Kararına konu teşkil eden olay şu şekilde cereyan eder:

A, mağdurlar B ve C'yi ıssız bir yere götürüp darp ettikten sonra onlardan kendisine kadın bulmalarını ister; mağdurların bulmayacaklarını söylemesi üzerine bu kez mağdur B'ye hitaben, "1.000 Lira getireceksin, C benim yanımda kalacak, C'yi sen parayı getirdikten sonra bırakacağım" şeklinde sözler söyler. Bunun üzerine B, C'nin evine giderek eşinden olayı anlatmaksızın ihtiyacı olduğundan bahisle para ister. B, C'nin eşinden aldığı bir miktar para ile bir çeyrek altını getirip A'ya verir. A, B'ye, "kalan 500 Lirayı Cuma gününe kadar bul" dedikten sonra, alıkoyduğu C'yi de serbest bırakır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu olayda mağdur adedince değil, **tek yağma suçunun** oluştuğu yönünde içtihatla bulunmuş ve iki ayrı yağma suçunun oluştuğunu kabul eden yerel mahkeme direnme hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

Şayet A, B ve C'yi muhatap alarak kendisine maddi menfaat temin etmeleri için her iki mağduru tehdit etmiş olsa veya her iki mağdura cebir uygulasa idi, olayda **iki ayrı yağma suçunun** varlığını kabul etmek gerekirdi ve failin **gerçek içtima** hükümlerine göre cezalandırılması gerekirdi (TCK, m. 43, f. 2 ve 3).

Oysa olayda A, C'yi alıkoyarak B'yi kendisine para temin etmesi hususunda tehdit etmiştir. Bu nedenle, CGK'nın kararında kabul edildiği gibi, olayda **bir yağma suçu** işlenmiştir.

rak ikrar elde etmek için bir yakınına cinsel saldırı niteliğinde davranışlarda bulunulması gibi olaylarda, bir fiille birden fazla kişiye **işkence** yapılabilir. Başka bir deyişle, bir fiille birden fazla kişiye karşı kasten öldürme, kasten yaralama, yağma ve işkence suçunun işlenmesi halinde, kişi **gerçek içtima** hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Kanun koyucu, bazı suçlar bağlamında özel olarak aynı neviden fikrî içtima hükmüne yer vermiştir. Örneğin, belirsiz sayıda kişilerin, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutulması halinde; **radyasyon yayma suçunun** temel şekline nazaran daha ağır ceza öngörülmüştür (m. 172, f. 2)¹²⁸¹.

Yukarıda da belirtildiği gibi, bir fiille birden fazla kişiye karşı hakaret edilmesi (m. 125) halinde, aynı neviden fikrî içtima durumu söz konusudur. Hakaret edilen kişinin kamu görevlisi olması halinde bu kuraldan ayrılmayı haklı kılan bir neden bulunmamaktadır. Ancak, hakaret suçunun tanımlandığı 125'inci maddenin beşinci fıkrasında yer verilen “*Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde, suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.*” şeklindeki hüküm, yanlış yorumlanarak, bu gibi durumlarda hakaret edilen kamu görevlisi sayısının cezaya hükmolunması gerektiği yönünde düşünceler ileri sürülmüştür. Bu yanlış anlaşılmanın önüne geçebilmek amacıyla, 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla TCK'nın 125'inci maddesinin beşinci fıkrasına, “*Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.*” şeklinde bir cümle eklenmiştir. Bu değişikliğin yapıldığı

Ancak, kararda göz ardı edilen bir husus vardır: C'nin hürriyetinden yoksun bırakılması. Olayda A tarafından, B'nin para temin etmeye zorlanması için C alıkonulmuş, yani hürriyetinden yoksun bırakılmıştır. Bu nedenle, A tarafından C'ye karşı işlenmiş **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu** işlenmiştir. A'nın ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılması gerekirdi. A'nın B ve C'yi kendisine kadın bulmaya zorlaması, yağma suçunu oluşturmaz. Ancak, bu zorlama bağlamında A'nın B ve C'ye tatbik ettiği darp fiilleri, kasten yaralama suçunu oluşturur. Olayda A tarafından B ve C'ye karşı işlenmiş **iki ayrı kasten yaralama suçu** söz konusudur ve failin bu suçlar nedeniyle **gerçek içtima** hükümlerine göre cezalandırılması gerekir. Ancak, bu darp fiilleri, B ve C'nin **belli bir şeyi yapmaları için** işlenmiştir. Bu nedenle, A hakkında TCK'nın “**Cebir**” başlıklı 108. maddesi hükmü gereğince, kasten yaralama suçundan dolayı verilen cezaların artırılması gerekmektedir.

Karardaki anlatımdan A'nın B ve C'yi zorla veya hileyle ıssız bir yere götürdüğü anlaşılmamaktadır. Bu nedenle, A tarafından B ve C'nin ıssız bir yere götürülmesi fiiliyle bağlantılı olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu oluşmamıştır.

¹²⁸¹ Keza, **kaçmaya imkan sağlama suçunda** (m. 294), kaçması sağlanan gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlü kişi sayısının birden fazla olması hâlinde de, bir cezaya hükmedilmekte, ancak verilecek ceza artırılmaktadır (f. 4). Ancak, belirtmek gerekir ki, bu durumda aynı neviden fikri içtima söz konusu değildir. Çünkü, kaçması sağlanan gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlü kişiler bu suçun konusu ise de mağduru değildir. Her ne kadar madde gerekçesinde söz konusu dördüncü fıkra hükmünün, “özel bir içtima hükmü” olduğu belirtilmiş ise de; kaçması sağlanan gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlü sayısının birden fazla olması, bu suç bakımından daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsur oluşturmaktadır.

5377 sayılı Kanunun esasını oluşturan TCK'da Değişiklik Yapılmasına Dair 2/452 sayılı Kanun Teklifinde şu **gerekçe**ye yer verilmiştir:

“Kanunun 43'üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen aynı neviden fikrî içtima halinde, bir fiille aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi söz konusudur. Bunun klasik örneğini, bir fiille birden fazla kişiye hakaret edilmesi oluşturmaktadır. Aynı neviden fikrî içtima halinde, bir suç vardır ve fail hakkında bir cezaya hükmolunur. Fakat, bu ceza zincirleme suç açısından belirlenen oranlarda artırılır. Bu kuralın istisnası, yine 43'üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, bir fiille birden fazla kişiye karşı işlenmiş olan kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında, fail gerçek içtima hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

Kanunun düzenlemesi bu yönde olmakla birlikte, 125'inci maddenin beşinci fıkrası hükmünün, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret edilmesi halinde kurulu oluşturan kamu görevlisi sayısınınca hakaret suçunun işlendiği şeklinde yanlış yorumlandığı gözlemlenmiştir. Bu yanlış anlaşılmayı gidermek amacıyla, söz konusu fıkra metnine "Ancak, bu durumda, aynı neviden fikrî içtima hükümleri uygulanır." şeklinde bir cümle eklenmiştir.”¹²⁸²

29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun esasını oluşturan TCK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifinde maddenin beşinci fıkrasına eklenmek istenen ikinci cümle *“Ancak, bu durumda, aynı neviden fikrî içtima hükümleri uygulanır.”* şeklinde idi. Fakat, TBMM Adalet Komisyonunda yapılan müzakereler sırasında bu cümledeki *“aynı neviden fikrî içtima hükümleri”* ibaresi, *“zincirleme suça ilişkin madde hükümleri”* olarak değiştirilmiştir. TBMM Adalet Komisyonunun 16.5.2005 tarihli ve Esas 2/452, Karar 79 sayılı Raporunda bu değişikliğin gerekçesi şu şekilde izah edilmiştir:

“Yeni Türk Ceza Kanununun 43'üncü maddesinin ikinci fıkrasında aynı neviden fikrî içtima düzenlenmiştir. Bu durumda, bir fiille aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi söz konusudur. Bunun klasik örneğini, bir fiille birden fazla kişiye hakaret edilmesi oluşturmaktadır. Aynı neviden fikrî içtima halinde, bir suç vardır ve fail hakkında bir cezaya hükmolunur. Fakat bu ceza, zincirleme suç açısından belirlenen oranlarda artırılır.

Zincirleme suç ile aynı neviden fikrî içtima arasındaki tek müştereklik, cezada yapılabilecek artırıma ilişkin oranlarının aynı olmasından ibaretir. Aslında birbirlerinden farklı durumlara ilişkin iki ayrı içtima hükmünün aynı maddede düzenlenmesinin tek nedeni budur. Ancak uygulamada tereddüt doğmasının önüne geçmek amacıyla Teklifte söz konusu maddenin beşinci fıkrasına eklenen son cümlede değişiklik yapılmıştır.”¹²⁸³

¹²⁸² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 4.

¹²⁸³ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 7/8.

Ekskurs 9: Yağma Suçu İle İlgili İçtima Sorunu ve Yargıtay Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler

Farklı zamanlarda aynı veya farklı kişilere karşı tehdit veya cebir kullanılarak haksız bir menfaat temin edilmesi durumunda her bir yağma fiili bağımsızlığını korur. Başka bir ifadeyle, TCK, m. 43, f. 3 düzenlemesi karşısında, bu gibi durumlarda her bir yağma fiilinden dolayı failin cezalandırılması gerekir. Failin bu gibi durumlarda her bir yağma fiilinden dolayı **gerçek içtima** hükümlerine göre ayrı ayrı cezalandırılabilmesi için, mağdurun aynı kişi veya farklı kişiler olduğunu bilmesine gerek bulunmamaktadır.

Yağma suçunun farklı zamanlarda **aynı kişiye karşı** müteaddit defa işlenmesi halinde, önceki yağma suçları teşebbüs aşamasında kalmış olabilir. Bu gibi durumlarda zincirleme şekilde işlenmiş suçtan söz edilebilir. Ancak, TCK, m. 43, f. 3 düzenlemesi karşısında, bu gibi durumlarda gerçek içtima hükümlerini uygulamak gerekir.

Bu bağlamda çeşitli olay örnekleri düşünülebilir:

Örnek olay 1. Tefecilikle iştigal eden A, B'ye aylık %4 faiz karşılığında altı ay vadeli 100.000 TL ödünç verir. Ancak B, bu parayı vadesinde ödeyemez. A, bu ana parayı ve faizini tahsil etmek için bulunduğu girişimlerden sonuç alamayınca, B'yi müteaddit defa telefonla arayarak ölümle tehdit eder. A, müteaddit defa B'yi tehdit etmesine rağmen parayı tahsil edemez. A, gerektiğinde tehdit veya cebir kullanarak bu parayı bir komisyon karşılığında tahsili hususunda C ile anlaşır. C bu anlaşmaya istinaden B'ye cebir kullanarak, bu parayı tahsil eder.

Bu örnekte, tefecilik konusu para ile faizinin tahsili amacıyla aynı kişiye karşı aynı veya farklı kişiler tarafından farklı zamanlarda cebir veya tehditte bulunulması halinde, **birden fazla yağma suçunun** işlenmiş ve bu suçlardan bir kısmının teşebbüs aşamasında kalmış olduğunu kabul etmek gerekir¹²⁸⁴.

Örnek olay 2. B, A ile oynadığı **kumarda** kaybeder ve A'ya 100.000 TL borçlanır. Ancak B bu parayı ödemekten imtina eder. A, bu **kumar parasını** tahsil etmek için bulunduğu girişimlerden sonuç alamayınca, B'yi müteaddit defa telefonla arayarak ölümle tehdit eder. A, müteaddit defa B'yi tehdit etmesine rağmen parayı tahsil edemez. A, gerektiğinde tehdit veya cebir kullanarak bu parayı bir komisyon karşılığında tahsili hususunda C ile anlaşır. C bu anlaşmaya istinaden B'ye cebir kullanarak, bu parayı tahsil eder.

Örnek olay 3. A, bir kamu kurumunun açtığı yapım ihalesine teklif vermek isteyen kişilerle tek tek görüşerek, teklif vermemeleri önerisinde bulunur ve iha-

¹²⁸⁴ Ancak, Yargıtay 6. Ceza Dairesi, bu gibi durumlarda “konunun özgülenmesi” gerekçesiyle bir yağma suçunun olduğu yönünde içtihatla bulunmuştur (Yargıtay 6. CD, **25.5.2022**, E. 2022/296, K. 2022/7816).

le kendisinde kalması halinde her birine 100.000 TL ödemeyi vaat eder¹²⁸⁵. Bu vaade dayanarak B ihaleye katılmaktan vazgeçer.

Ancak A, ihaleye katılan sair isteklilerin fiyatı indirmesi sebebiyle bu parayı ödemekten imtina eder. B, bu parayı tahsil etmek için A'yı müteaddit defa telefonla arayarak ölümle tehdit eder. A, müteaddit defa B'yi tehdit etmesine rağmen parayı tahsil edemez. A, gerektiğinde tehdit veya cebir kullanarak bu parayı bir komisyon karşılığında tahsili hususunda C ile anlaşır. C bu anlaşmaya istinaden B'ye cebir kullanarak, bu parayı tahsil eder.

Bütün bu örnek olaylarda, **haksız menfaat** temini amacıyla aynı kişiye karşı aynı veya farklı kişiler tarafından farklı zamanlarda cebir veya tehditte bulunulmuştur. Bu tür olaylarda **birden fazla yağma suçu** işlenmiş ve bu suçlardan bir kısmı **teşebbüs** aşamasında kalmıştır.

Ancak Yargıtay, bu gibi durumlarda yağma suçundan dolayı gerçek içtima hükümlerine istinaden verilen ceza miktarının çok yüksek miktarlara balığ olması karşısında, “*konunun özgülenmesi*” ölçütü geliştirerek, faile bir ceza verilmesi yoluna gitmektedir. Buna göre, aynı parasal değer elde edilmesi amacıyla aynı kişiye ve hatta farklı kişilere müteaddit defa cebir veya tehdit uygulanması halinde, **yağma** suçundan dolayı **bir mahkûmiyet hükmü** kurulmaktadır¹²⁸⁶.

¹²⁸⁵ Bu olay bağlamında yapılan değerlendirmelerde, ihaleye katılmak isteyen kişilere ihaleye katılmaktan vazgeçmeleri için para vaat edilmesinin ve bu vadin kabulünün TCK, m. 235’de tanımlanan **ihaleye fesat karıştırma suçu**nu oluşturduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

¹²⁸⁶ Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aynı mağdurun müteaddit defa çeşitli suretlerde tehdit edilerek her defasında çeşitli malvarlığı değerlerinin alındığı bir olayda, aşağıdaki gerekçe ile bir yağma suçunun oluştuğu yönünde içtihatla bulunmuştur:

“*Sanıkların iradesi baştan itibaren mağdurdan belirli bir miktar parayı almaya özgülenmiş olup, ilk eylemden sonra gerçekleştirdikleri fiillerin en başta aldıkları diğer eşyalar ile birlikte almayı hedefledikleri ... Lirayı da mağdurdan almaya yönelik olduğu anlaşıldığından, sanıkların eylemlerinin tek nitelikli yağma suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.*” (Yargıtay CGK, **20.5.2014**, E. 2013//6-617, K. 2014/271).

Oysa bu olayda, mağdura karşı farklı zamanlarda birden fazla **tamamlanmış** yağma suçu işlenmiştir ve faillerin her bir yağma suçundan dolayı ayrı ayrı cezalandırılmaları gerekirdi. Belirtmek gerekir ki, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun söz konusu kararı, oy çokluğu ile verilmiştir.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin **20.4.2022** tarihli ve E. 2021/17414, K. 2022/5983 sayılı kararına konu teşkil eden, belirli bir miktar paranın yağmalanması olayında, F, M’yi müteaddit defa telefonla arar ve “*senin ölen annen bize adam vurdurttu. 50.000 lira verecekti. 25.000 lirayı vermeden öldü. Bu miktarı vermeden öldü ... Bu parayı sen vereceksin ... vermezsen sen de ölürsün*” diyerek tehdit eder. M, bu tehditlerin etkisiyle F’ye 25.5.2015 tarihinde 14.000 TL ödeme yapar. F, aradan 1 yıl 1 ay 10 gün bir zaman geçtikten sonra tekrar M’yi tehdit ederek 11.000 TL daha tahsil etmek ister.

İlk derece mahkemesi, bu olayda, birincisi tamamlanmış, ikincisi teşebbüs aşamasında kalmış, iki ayrı yağma suçunun oluştuğunu kabul ederek, F hakkında mahkûmiyet hükümleri kurmuştur.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, birinci dilim paranın alınmasıyla ikinci dilim paranın alınmasına yönelik tehdidin icrası arasında geçen zamanın aynı suç işleme kararı kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle, ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet hükümlerinin onanmasına karar vermiştir.

Bu kararda, birinci dilim paranın alınması bağlamında failin farklı zamanlarda, müteaddit defa telefonla arayarak mağduru tehdit etmesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.5.2014 tarihli ve E. 2013/6-617, K. 2014/271 sayılı kararı esas alınarak ve aşağıdaki gerekçe ile, **tek fiil** sayılmış ve tamamlanmış bir yağma suçunun oluştuğu kabul edilmiştir.

“TCK, m. 43, f. 3’deki istisna dolayısıyla, “zaman zaman suç ve cezada orantılılık ve hakka-niyet ilkelerine aykırı, işlenen fiilin haksızlık içeriğiyle bağdaşmayan ağır cezalar ortaya çık-tığı düşüncesinden hareketle,” yağma suçunun belli bir miktara veya bir malvarlığına özgü-lenmesi hâlinde, somut olayda değişik zamanlarda işlenen birden fazla fiil olsa ve hatta bir-den fazla kişinin mağduriyetine sebep olunsu bile, fiilin hukuki anlamda tekliği kavramını ge-niş yorumlanmak suretiyle bir yağma suçunun işlendiği kabul edilmektedir.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 7.2.2012 tarihli ve E. 2011/6-332, K. 2012/21 sayılı kararı-na konu olan olayda; A, mağdurları tehdit ederek ve mağdurlardan C’yi yanında alıkoyarak B’nin kendisine bir miktar para bulup getirmesini ister. B de, C’nin evine giderek eşine ait bir miktar para ve altını alır ve getirip A’ya verir. Bunun üzerine, A, bir miktar daha para getir-meleri gerektiğini beyanla, yanında tuttuğu C’yi serbest bırakır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu olayda da, aşağıdaki gerekçe ile, **bir yağma suçunun** oluştuğunu kabul etmiştir.

*“Sanığın iradesi baştan itibaren mağdur B’den belirli bir miktar para almaya özgülenmiş olup, gerçekleştirdiği fiiller amaçlanan yağma suçuna yönelik olduğundan **sanığın eylemleri mağdur adedince değil** yalnızca amaçlanan **tek yağma suçunu** oluşturmaktadır. Sanığın, mağdur B’den istediği parayı getirmesi için mağdur C’yi yanında alıkoyarak hürriyetini kısıt-laması, mağdur B’nin istenen parayı mağdur C’nin eşinden olayı anlatmadan alarak getirme-si, sanığın istediği paranın eksik kalan kısmı için mağdur B’ye yönelik “kalan 500 Lirayı cu-ma gününe kadar bul” şeklinde tehditte bulunması da sanığın eylemlerinin bütününe tek bir yağma suçunu oluşturduğu kabulünü değiştirmeyecektir. Bu nedenle olayın gelişimi, sanığın eylemlerinin B’den belirli miktardaki parayı yağmalamaya yöneldiği ve sanığın kastı göz önüne alınmaksızın, mağdur B’ye karşı yağma suçunu işlemek amacıyla mağdur C’ye karşı gerçekleştirilen ve bu mağdurun malvarlığına yönelmeyen fiillerden hareketle, iki ayrı yağma suçunun oluştuğunu kabul eden yerel mahkeme direnme hükmü isabetsizdir.”*

Oysa bu olayda iki kişiye birden işlenmiş bir yağma suçu bulunmaktadır. Aynı suç birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmiştir. Bu durumda aynı neviden fikri içtima (TCK, m. 43, f. 2) hükümlerini göz önünde bulundurmak gerekir. İki kişiye birden tehditte bulunularak hak-sız bir menfaat temin edilmeye çalışılmış ve temin edilmiştir. Ancak, TCK, m. 43, f. 3 hükmü karşısında, bu durumda aynı neviden fikri içtima hükümlerini değil, **gerçek içtima** hükümle-rini uygulamak, yani mağdur edilen, haksız menfaat teminine matuf olarak cebir uygulanan veya tehdit edilen kişi sayısınca tamamlanmış (veya duruma göre teşebbüs aşamasında kal-mış) yağma suçundan dolayı cezaya hükmetmek gerekir.

Söz konusu olayda ayrıca, C hürriyetinden yoksun bırakılmıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, yağma suçunun bir unsurunu oluşturmamaktadır. C hürriyetinden yoksun bırakılarak, kendisine karşı bir kötülük ika edileceği izlenimi oluşturulmuş ve bu suretle B’nin iradesi zor-lanmış, tehdide maruz bırakılmıştır. B, bu zorlamanın etkiyle, temin ettiği bir miktar para ve sair malvarlığı değerini getirip A’ya teslim etmiştir. Bu durumda A hakkında ayrıca **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan** (TCK, m. 109) dolayı mahkûmiyet hükmü kurulması gerekirdi.

Karara konu teşkil edilen olayda bu durum göz önünde bulundurularak, **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun** yanı sıra **bir yağma suçundan** dolayı mahkûmiyet hükmü kurulması, daha doğru olurdu.

Belirtmek gerekir ki, bu uygulama, hukukî ilişkiye dayanan alacağın tahsili maksadıyla kişiye cebir veya tehdit uygulanması durumu ile çelişmektedir. Şöyle ki, hukukî ilişkiye dayanan belirli bir miktar alacağın tahsili amacıyla aynı kişiye farklı zamanlarda müteaddit defa **tehdit** uygulanması halinde, **zincirleme suç** hükümleri uygulanabilecektir. Hukukî ilişkiye dayanan belirli bir miktar alacağın tahsili amacıyla aynı kişiye müteaddit defa tehdit uygulanması halinde, tehdit suçunun müteselsilen işlendiğini kabul etmek ve TCK, m. 43, f. 1 hükümlerini uygulamak gerekir. Hatta, hukukî ilişkiye dayanan belirli bir miktar alacağın tahsili amacıyla aynı kişiye müteaddit defa cebir uygulanması halinde, her bir **kasten yaralama** suçu dolayısıyla **gerçek içtima** hükümlerine göre cezalandırma yolu gitmek gerekecektir (TCK, m. 43, f. 3).

Yargıtay, tek fiil ile birden fazla kişiye karşı yağma suçunun işlendiği hallerde de tek yağma suçunun oluşacağını kabul etmektedir¹²⁸⁷.

¹²⁸⁷ Yargıtay 6. Ceza Dairesinin **21.12.2021** tarihli ve E. 2021/23652, K. 2021/19944, sayılı kararına konu olan olayda; A ve B, C ve D'den maddi menfaat temin etmek isterler. Korkuya kapılan C elerini kaldırır ve A, C'nin cebinde bulunan iki adet mobil telefonu alır. C ve D telefonları geri almaya çalışır ise de, A bıçakla bu kişileri korkutarak B ile birlikte olay yerinden uzaklaşır.

Yargıtay 6. CD'si, bu olayda A ve B'nin **tek yağma suçundan** sorumlu tutulması gerektiğine karar vermiştir.

Aslında bu olayda bir fiille birden fazla kişiye karşı işlenmiş **bir yağma suçu** mevcuttur ve **aynı neviden fikri içtima** durumu (TCK, m. 43, f. 2) söz konusudur. Ancak, TCK, m. 43, f. 3 düzenlemesi karşısında, bu durumda da **mağdur sayısınınca yağma suçundan** dolayı cezaya hükmetmek gerekir.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin **8.6.2022** tarihli ve E. 2022/51, K. 2022/8722 sayılı Kararına konu olan olayda; S, Emrah, Esra ve Nurgül'ün çalıştıkları markete gelerek elindeki av tüfeği ile bu kişileri tehdit eder ve cep telefonlarını alır. Esra'ya Emrah ve Nurgül'ün ellerini plastik kelepçe ile kelepçelemesini sağlar. Keza, Esra'nın kasaları anahtarla açmasını sağlayarak, toplam 6.750 TL parayı alır. Akabinde de, bu kişileri markette bir ofise kilitleyerek olay yerinden ayrılır.

İlk derece Mahkemesi, bu olayda S hakkında,

- nitelikli yağma suçundan dolayı TCK, m. 149, f. 1, bent a, d, h; m. 62 hükümlerine istinaden 10 yıl hapis cezasına,

- kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı TC, m. 109, f. 2, f. 3, bent a; m. 110; m. 62 hükümlerine istinaden ve mağdur sayısınınca üç kez 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına,

hükmetmiştir.

S hakkında yağma suçundan dolayı verilen mahkûmiyet hükmünün onanmasına karar veren Yargıtay 6. Ceza Dairesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı kurulan mahkûmiyet hükmünün aşağıdaki gerekçe ile bozulmasına karar vermiştir:

“Doğal anlamda birden fazla olmakla birlikte hukuki anlamda tek bir fiil ile aynı suçun birden fazla mağdura karşı işlenmesi hali söz konusu olduğundan, 5237 sayılı TCK'nın 43/2. maddesinde düzenlenen aynı neviden fikri içtima hükümleri uyarınca sanık hakkında tek bir ceza verilip bu cezanın artırılması gerekirken, mağdur sayısınınca üç kez mahkûmiyet kararı verilmesi,” hukuka aykırıdır.

Bu karara konu teşkil edilen olayda, S, hukuki anlamda **bir fiille birden fazla kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu** işlemiştir. Bu suç bakımından **aynı neviden fikri içtima**

V. Farklı Neviden Fikrî İçtima

I. Farklı neviden fikrî içtima halinde, **bir fiil** ile kanunda tanımlanan **birden fazla farklı suç** işlenmektedir. Bu suçların her birinden ayrı ayrı cezalandırılabilme imkânı varken; Kanun koyucu faile **bu suçlardan en ağırının cezasının** verilmesi ilkesini benimsemiştir.

Buna göre; farklı nev’iden fikrî içtimadan söz edebilmek için, a) fiilin tek olması, b) bu fiil ile kanunda tanımlanan birden fazla suçun işlenmesi gerekir.

765 sayılı TCK’nın 79’uncu maddesinin ifade biçimine göre, “*İşlediği bir fiil ile kanunun muhtelif ahkâmını ihlâl eden kimse o ahkâmdan en şedit cezayı tazammun eden maddeye göre cezalandırılır.*” Bu ifade biçiminde, işlenen bir fiille kanunun farklı hükümlerinin ihlâlinden söz edilmekteydi¹²⁸⁸. Bu ifade bi-

hükümlerini uygulamak gerekir. Keza S, hukuki anlamda **bir fiille** birden fazla kişiye karşı **bir yağma suçu** işlemiştir. Yağma suçu bakımından da **aynı neviden fikrî içtima**ın (TCK, m. 43, f. 2) söz konusu olduğu bu durumda S hakkında, **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun** yanı sıra, **mağdur sayısınca yağma suçundan** dolayı cezaya hükmetmek gerekir.

¹²⁸⁸ «Fikrî içtima, kısaca “kanunların gerçek içtimaı” olarak tanımlanmaktadır. Zira, fiil kanunun birden çok hükmünü ihlâl etmiştir. Bu normların ayrı ayrı uygulanabilme imkânı varken; kanun koyucu 79. madde ile faile bu suçlardan en ağırının cezasının verilmesi ilkesini benimsemiştir.

Buna göre; fikrî içtimadan söz edebilmek için, a) fiilin tek olması, b) kanunun değişik hükümlerine aykırı davranılması gerekir»: CGK., 10.12.1990, 1-310/333 (YKD, Kasım 1991, sh. 1700 vd.).

«Ceza Kanunumuzun 79. maddesi; suçların içtimaı hallerinden birini oluşturan *fikrî içtimaı* hükme bağlamakta ve en ağır hükme göre fiilin cezalandırılacağıı belirtmektedir. Bu suretle her ihlâlin ayrı suç oluşturacağı ve bunların ayrı ayrı cezalandırılacağı kuralından ayrılmıştır.

Fikrî içtima için; birden çok suçu sonuçlayan *tek ve aynı fiilin* bulunması; her suç(a) ilişkin olarak, bu) fiilin kanunî tarife uygun (ve) hukuka aykırı ... olması ... ve ayrıca, farklı kanun hükümlerini ihlâl etmesi gerekir. Bu niteliklerden herhangi birini taşımayan hallerde fikrî içtima değil, gerçek içtima durumu vardır.

Fiil ile ceza normları arasındaki ilişki yönünden gerçekleşmesi mümkün bir durum da; çeşitli normların aynı fiille ilgili görünmelerine rağmen aslında bunlardan yalnız birinin fiile uygulanabilmesidir. Fikrî içtimada fiille ilgili bir çok norm bulunmakta ve bunlar çeşitli yönleriyle fiili değerlendirmekte, çeşitli suçları sonuçlamakta, ancak kanun koyucu suçların çokluğunu bir yana bırakarak faili en ağır suçtan sorumlu tutup cezalandırılmaktadır. Doktrinde “*görünüşte içtima*”, “*normların içtimaı*” veya “*görünüşte fikrî içtima*” olarak isimlendirilen bu haller, aynı şeyi ifade etmektedir. Fiille ilgili birden çok ceza normu bulunmasına rağmen, bunlardan sadece biri fiilin hukuka aykırılığını kapsaması yönünden yeterli bulunmaktadır. Özel normun önceliği ilkesi, bu normun diğeri tarafından tüketilmesi ilkesi ve yardımcı normun sonralığı ilkesi, görünüşteki içtimaın ilkelerini oluşturmaktadır.»: CGK., 12.3.1984, 1-176/87 (Savaş/Mollamahmutoğlu III, 4172 vd.). Aynı mealde CGK., 1-174/86 (Savaş/ Mollamahmutoğlu III, 4186 vd).

«Sanık M’nin yeğeni G, L için, O, C ve T tarafından kaçırılmış(tır. B)u olayı ... öğrenen M, av tüfeği(yle) yeğenini kaçırılanları takibe başlamıştır. ... (G)ece saat 20.30 sıralarında karşıdan gelen bir otonun ışığını farkedene M, otoda O, C ve T’nin olduğunu tahmin ederek, otonun cam hizasına geldiğinde yakın mesafeden bir el ateş edip, jip şoförü B ile jipin arkasındaki O’yu yaralamış ve (ayrıca,) jipin arkasındaki jandarma eri S’yi öldürmüştür.

M’nin ateş ettiği jip, kız kaçırma olayını soruşturmak ve sanıkları yakalamak için köye gelen ve kaçırma suçu sanıklarından O’yu elde ederek karakola götüreren Karakol Komutanı emrindeki jiptir.

çiminin doğru olmadığını öncelikle ifade etmek gerekir. Çünkü, işlenen fiil kanundaki tanıma uygun olduğu takdirde suç oluşturmaktadır. Suç oluşturan fiil, ceza kanununa aykırı veya ceza kanununu ihlal eden fiil değildir; aksine, davranış normlarına ve dolayısıyla kişinin yükümlülüklerine aykırı bir fiildir. Bu ba-

Bu oluşa göre; M, hasımlarının bulunduğu kanısıyla ve bunların tümünü öldürmek kastıyla jipe ateş etmiştir.

Hal böyle olunca; TCK'nın 79. maddesinin *uygulanmaması* gerekir. M, kullandığı av tüfeğindeki şevrotinlerin dağılacağı ve jipte üç hasmının da bulunduğu bilinci ve kastı ile ateş etmiştir. M'nin, ölen jandarma erine öldürme kastıyla ateş etmediğinden, TCK. 52. maddesi delâletiyle 448. maddesine göre mahkûm edilmesi doğrudur: CGK., 9.3.1981, 6/84 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1109).

1475 sayılı Kanunun 2869 sayılı Kanun ile değişik 85 ve 105. maddelerinde “*dış ülkelere işçi göndermek amacıyla*”, “*işçilere iş ve işlere işçi bulmak için faaliyet gösterilmesi, çalışılması ve büro açılması*” suç sayılmış ve bu fiiller işlenirken kazanç amacının güdülüp güdülmemesi aranmamıştır. Bu suçun ihdasıyla korunan hukuki değer, “malvarlığı değil, kamu düzenidir, devlet iş işi bulmayı tekeline alarak bunu kamu düzeninden saymıştır”. “Bu fiillerin içten ve iyiniyetle yapılmış olması halinde dahi, suç oluşacaktır”. Buna karşılık; dolandırıcılık suçunda iyiniyet yoktur; aksine, iyiniyetin sömürülmesi sözkonusudur: SELÇUK Sami: CGK.’nın 30.3.1987 tarih ve 6-441/154 sayılı Kararına muhalefet şerhi (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1061 vd. [1070]; Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 1172 vd.).

1475 sayılı Kanunun 85 ve 105. maddelerinde tanımlanan suç ile Ceza Kanununun 503. maddesinde tanımlanan suç arasında yapıları gereği fikrî içtima olmadığı gibi, konuları ayrı olduğundan özel-genel hüküm ilişkisi de yoktur. 1475 sayılı Kanunun 105. maddesindeki suç, bir tür “engelleme suçu”dur ve kanunkoyucu bu tür davranışların doğurabilecekleri dolaylı zararlardan kişileri korumak istemiştir. Bu itibarla; fail iyiniyetle işçiye iş bulmak istemişse, para alsın veya almasın, sadece 1475 sayılı Kanunun 85 ve 105. maddelerinde tanımlanan suç oluşur. Fail, kötüniyetle, sömürmek için bu faaliyette bulunmuş ve ayrıca kazanç da sağlamışsa, iki suç birden oluşur ve gerçek içtima hükümleri uygulanır: SELÇUK Sami: CGK.’nın 30.3.1987 tarih ve 6-441/154 sayılı Kararına muhalefet şerhi (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1061 vd. [1070]).

Fikrî içtima açısından Türk Ceza Kanunu ve Kaynak Kanunun benimsediği ölçüt *maddi netice ölçütüdür*: SELÇUK Sami: CGK.’nın 30.3.1987 tarih ve 6-441/154 sayılı Kararına muhalefet şerhi (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1061 vd. [1065, 1072]).

Yargıtay, tek sözle birden çok kişiye sövülmesi halinde; *mağdur ölçütüne* göre kişi sayısınca suç saymaktadır.

Sahte evrak, dolandırıcılık suçunun sania unsurunu oluşturmaktadır. Ancak, dolandırıcılık suçunun oluşumu açısından sania, sahte evraktan ibaret değildir. Sahte evrak, sanianın sadece bir çeşidini oluşturmaktadır. Diğer taraftan, sahtekârlık, özel evrakın kullanılmasıyla oluşur. Ancak, dolandırıcılık suçu açısından sahte evrakın kullanılmasının yanısıra, haksız bir menfaatin temin edilmesi ve dolayısıyla, bir başkasının malvarlığında bir azalmanın olması gerekir. Halbuki özel evrakta sahtekârlık fiilinden bir haksız menfaat elde edilmiş olup olmamasının suçun oluşumu açısından bir önemi yoktur: SELÇUK Sami: CGK.’nın 30.3.1987 tarih ve 6-441/154 sayılı Kararına muhalefet şerhi (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1061 vd. [1065]).

«Sanıklar H ve M, diğer sanık F’nin eşi ile gayrimeşru ilişki kuran A’ya öldürmek amacıyla yaptıkları atışları sırasında rastlantı sonucu mağdur O’nun da yaralandığı; birden fazla yara almasının motosiklette arka arkaya oturmalarından kaynaklandığı; bu itibarla, mağdur O’ya yönelik bir kastın varlığı düşünülemez. Bu oluşa göre, TCK’nın 79. maddesi uyarınca sanıkların maktulü (A’yi) öldürmekten sorumlu tutulmaları gerekirken; mağdur O’nun da yaralanmasından dolayı ayrıca hükümlendirilmeleri bozmayı gerektirmiştir.»: 1. CD., 28.1.1988, 4265/147 (Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 1197).

kımdan, yeni TCK'nın farklı neviden fikrî içtimanın düzenlendiği 44'üncü maddesinin ifadesi, 765 sayılı Kanununki ile aynı değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi, farklı neviden fikrî içtima halinde, **bir fiil** ile kanunda tanımlanan **birden fazla farklı suç** işlenmektedir^{1289,1290,1291}.

Suçların içtimasının bu şekli ile ilgili olarak şu örnek olaylar göz önünde bulundurulabilir:

Evi yakılarak kişinin öldürülmesi halinde, hem genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu (m. 170), hem de kasten öldürme suçunun nitelikli hali (m. 82, f. 1, bent c) işlenmektedir¹²⁹².

¹²⁸⁹ Farklı neviden fikri içtimanın şartları hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. GÖKTÜRK, Fikri İçtima, sh. 180 vd.

¹²⁹⁰ Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20.03.2008 tarihli ve E. 2007/118, K. 2008/170 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, önleme amaçlı olarak yapılan arama sırasında, S'nin üzerinde bir adet silah ve şarjör ile bir adet sustalı bıçak ele geçirilir.

Ekspertiz incelemesi sonucu düzenlenen raporda, söz konusu silahların 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince yasak olan ve bulundurulması suç teşkil eden silahlar olduğu tespit edilmiştir.

Mahkeme, bu olayda S'nin "*hem bıçak hem de silahı taşıyarak ayrı ayrı fiilleri ayrı suç işlemek kastı ile hareket ederek müsnet suçu işlediği*"ni kabul eder ve hakkında 6136 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca **iki defa** cezaya hükmeder (**gerçek içtima**).

Aynı yönde diğer bir karar için bkz. Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 14.5.2010, E. 2009/724, K. 2010/361.

Not: Ele geçirilen bıçağın bulundurulması, 6136 s. Kanunun 4. maddesiyle yasaklanmış olup, bu yasağa aykırılık, aynı Kanunun 15. maddesinde tanımlanan suçu oluşturmaktadır. Bu suçun temel şekli için Kanunda öngörülen ceza, altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezasıdır (m. 15, f. 1).

Buna karşılık, ateşli silahın ve şarjörünün ruhsatsız olarak bulundurulması ise, 6136 s. Kanunun 13. maddesinde tanımlanan suçu oluşturmaktadır. Bu suçun temel şekli için Kanunda öngörülen ceza, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasıdır (m. 13, f. 1).

Bu durumda Yargıtay, bir fiille iki ayrı suçun işlendiğinin kabulüyle, **farklı neviden fikri içtima** (TCK, m. 44) hükümlerinin uygulanması yönünde içtihatla bulunmuştur. Yargıtay'a göre, bu olaylarda, daha ağır cezayı gerektirmesi itibarıyla 6136 s. Kanunun 13. maddesi hükmüne istinaden cezaya hükmedilmesi ve cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerekir (8.CD, 6.2.2012, E. 2010/6577, K. 2012/2866; aynı Daire, 28.5.2012, E. 2011/857, K. 2012/18060; aynı Daire, 6.3.2012, E. 2010/9839, K. 2012/6958).

¹²⁹¹ Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'nin 30.3.2010 tarihli ve E. 2009/73, K. 2010/77 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, S, M'ye ait araziye, iş makinesiyle girerek, arazide bulunan ağaçları tahrip eder ve toprağı kaldırır.

Bu olayda Mahkeme, S'yi, hakkı olmayan yere tecavüz suçunu (TCK, m. 154, f. 1) ve mala zarar verme suçunun nitelikli halini (TCK, m. 152, f. 1, bent c) işlediğini kabul ederek, **doğru** olarak, **her iki suçtan** dolayı **ayrı ayrı** cezalandırır (**gerçek içtima**).

Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, söz konusu olay bağlamında, "*TCK'nın 44. maddesinde düzenlenen (farklı neviden) fikri içtima kuralı gereğince bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren sanığın bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması ile yetinilmesi gerektiği*" yönünde içtihatla bulunmuştur (9. CD, 27.11.2012, E. 2012/1192, K. 2012/13738).

¹²⁹² "Oturduğu masa kenarında bulunan kapalı camdan dışarı havaya doğru art arda beş kez ateş eden sanığın "ateş etme" eylemlerinin **hukuki anlamda tek fiil** sayılması gerektiğinde ve bu

Gözlüklü bir kişinin gözüne yumruk vurularak kasten yaralama suçu (m. 86 veya 87) işlenirken, aynı zamanda mala zarar verme suçu da (m. 151) işlenmektedir.

Kişiye işkence yapılırken (m. 94), aynı zamanda kasten yaralama (m. 86), hakaret (m. 125) ve tehdit (m. 106) gibi suçlar da işlenmektedir.

Bir suçun temel ve nitelikli şekillerinin dışındaki suçlar, fikrî içtima uygulamasında farklı suç olarak kabul edilmelidir.

Farklı neviden fikrî içtima halinde, bir fiille işlediği birden fazla farklı suçların her birinden dolayı failin ayrı ayrı cezalandırılması yoluna gidilmemektedir. Kanun koyucu faile **bu suçlardan en ağırının cezasının** verilmesi ilkesini benimsemiştir. Böylece “erime sistemi”ne taraftar olunmuştur.

Ancak, Kanun koyucu, bazı suçlar bağlamında, farklı neviden fikrî içtimanın varlığına rağmen, en ağır cezayı gerektiren suçun cezasının belli bir oranda artırılmasını öngörmüştür. Örneğin, ceza infaz kurumunda silah ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma halinde, TCK’nın 297. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suç oluşmaktadır. Esasında silah ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma başlı başına bir suç oluşturmaktadır (m. 174, 188, 191). Bu duruma özgü olarak Kanun koyucu, işlenen suçlardan en ağırına göre verilecek cezanın belirli bir oranda artırılmasını öngörmüştür (m. 297, f. 1)¹²⁹³.

Yeni TCK’ya ilişkin olarak TBMM Adalet Komisyonunda yapılan çalışmalar sırasında, farklı neviden fikrî içtima halinde faile verilecek cezanın bir suç işleyen kişinin cezasından farklı olması gerektiği düşüncesiyle, işlenen suçlardan en ağırına göre verilecek cezanın belirli bir oranda artırılması hususunda hakime takdir yetkisi tanınması yönünde öneride bulunmamıza rağmen, bu önerimiz kabul görmemiştir.

II. TCK’nın 43. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü karşısında, bir fiille birden fazla kişiye karşı kasten yaralama veya kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde, söz konusu maddenin aynı neviden fikrî içtima ile ilgili ikinci fıkrası hükmü uygulanamayacaktır. Bu itibarla, bir bomba patlatılması sonucunda birden fazla kişi yaralanmışsa, yaralanan kişi sayısınca kasten yaralama suçunun işlendiğini kabul etmek gerekecektir. Keza, bir bomba patlatmak suretiyle birden fazla kişi öldürülmüşse, ölen kişi sayısınca kasten öldürme suçu işlenmiş olacaktır.

Buna karşılık, bir bomba patlatılması sonucunda,

a) bir kişi ölmüş ve birden fazla kişi yaralanmış olabilir;

şekilde, tek olan eylem sonunda hem **mala zarar verme** suçunun, hem de **genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması** suçunun oluştuğunda şüphe bulunmadığından, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesinde düzenlenmiş bulunan **farklı nev’iden fikrî içtima** hükümlerinin uygulanması ve oluşan suçlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan ceza verilmesi gerekmektedir.” CGK, 10.12.2013, E. 2012/9-1456, K. 2013/608.

¹²⁹³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. CGK, 24.12.2013, E. 2013/10-641, K. 2013/623.

- b) birden fazla kişi ölmüş ve bir kişi yaralanmış olabilir;
- c) bir kişi ölmüş ve bir kişi de yaralanmış olabilir;
- d) birden fazla kişi ölmüş ve birden fazla kişi yaralanmış olabilir.

Bu ihtimallerde sorun, yukarıda olası kastla işlenen suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanabilirliği ile bağlantılı olarak yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi, yaralama neticeleri bakımından **olası kastla yaralama suçunun** mu yoksa **olası kastla öldürme suçuna teşebbüsün** mü oluştuğu hususunda temerküz etmektedir. Klasik anlayışta, bu ihtimallerde yaralama neticeleri bakımından *olası kastla yaralama suçu* oluştuğu kabul edildiği için, farklı neviden fikri içtima (TCK, m. 44) hükümlerinin uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır¹²⁹⁴. Oysa bu gibi hallerde, yaralama neticeleri bakımından olası kastla yaralama suçunun değil, **olası kastla öldürme suçuna teşebbüsün** oluştuğu kabul edildiği takdirde, sorun kolaylıkla çözümlenebilmektedir.

Buna göre, söz konusu ihtimallerde, ölen kişi sayısınınca **tamamlanmış doğrudan veya olası kastla öldürme suçunun** ve keza, yaralanan kişi sayısınınca da **teşebbüs aşamasında kalmış olası kastla öldürme suçunun** oluştuğunu kabul etmek gerekecektir. Başka bir ifadeyle, yukarıda sözü edilen dört ihtimalde de, TCK, m. 43, f. 3 hükmüne istinaden **gerçek içtima** hükümlerinin uygulanması gerektiği kanısındayız¹²⁹⁵.

III. Yeni TCK’da hedefte sapma hâli ile ilgili olarak özel bir hüküm (765 s. TCK, m. 52) bulunmamaktadır. Bu nedenle, hedefte sapma halinde, aynı veya farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekir.

765 s. TCK’nın sisteminde, *hedefte sapma*, suçun unsurlarındaki hata ile birlikte aynı madde kapsamında düzenlemişti.

«Bir kimse bir hata veya sair bir ârıza yüzünden cürmü kastettiği şahıstan başka bir şahsın zararına işlemiş olursa; cürümden zarar gören kim-

¹²⁹⁴ Bu çözüm biçimi bakımından Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **5.2.2019** tarihli ve E. 2018/310, K. 2019/62 sayılı; **16.9.2014** tarihli ve E. 2013/9-431, K. 2014/377 sayılı; **3.12.2013** tarihli ve E. 2012/1-1569, K. 2013/575 sayılı kararlarında gerekçe olarak yer verilen açıklamalar ve varılan sonuçlar önemlidir.

¹²⁹⁵ Her ne kadar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **10.12.2013** tarihli ve E. 2012/1-1572, K. 2013/600 sayılı kararında belirtilen durumlarda **gerçek içtima** hükümlerine göre cezaya hükmedilmesi gerektiği yönünde de içtihadta bulunulmuş ise de; bu sonuca klasik suç teorisindeki “hareket+netice=fiil” anlayışından varılmıştır.

Bu karara konu teşkil eden olayda; S, kardeşi E’yi öldürmek kastıyla iki el ateş eder. Ancak, tabancadan çıkan mermi çekirdekleri E’ye isabet etmez; bunlardan biri E’nin hemen yanında bulunan yengesi L’ye isabet ederek yaralanmasına sebebiyet verir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu içtihadında, mülga 765 sayılı TCK’nın yürürlükte olduğu dönemdeki içtihatlarında olduğu gibi, **fiil sayısını gerçekleşen neticeye göre** belirlemiştir.

senin sıfatından neşet eden ve cezayı şiddetlendiren esbap faille tahmil olunmaz. Belki cürüm kastolunan şahsa karşı işlenmiş gibi telâkki olunarak; fail, cürmün tazammun edebileceği esbabı muhaffifeden istifâde eder.» (m. 52)

Halbuki hedefte sapma halinde, bir yanlış söz konusu değildir. Hareket neticesini, istenen konu üzerinde değil, sapma sonucu bir başka konu üzerinde gerçekleştirmektedir.

Sapma halinde konular farklı nitelikte olabilir. Meselâ, camı kırmak için atılan taş, A'ya isabet eder. Bu durumda kişiyi teşebbüs aşamasında kalmış mala zarar verme suçundan (m. 151) ve ayrıca, olası (muhtemel) kastla ya da taksirle gerçekleştirdiği yaralama suçundan (m. 86 – 89) dolayı sorumlu tutmamız gerekecektir.

Konular aynı nitelikte de olabilir. Meselâ, A öldürülmek istenirken, mermi sekmesi sonucu B ölmüştür. Bu durumda kişiyi A açısından teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürme suçundan ve ayrıca, B açısından tamamlanmış öldürme suçundan dolayı sorumlu tutmamız gerekir. Ancak, hedefte sapma sonucu meydana gelen ölümden (B'nin ölümünden) dolayı faili sorumlu tutarken, bu ölümle alakalı olarak olası (muhtemel) kastla mı yoksa taksirle mi hareket ettiğini araştırmak gerekir¹²⁹⁶.

Ancak, 765 s. TCK'nın 52. maddesinin kabul ettiği çözüm şekline göre, bu durumda *tamamlanmış bir tek suç* söz konusudur¹²⁹⁷ ve suçun konusunda veya mağdurun kimliğinde yanılmaya ilişkin esaslara göre mesele çözümlenmektedir. Suçun konusunda yanılma ile hedefte sapma arasında bir ayırım gözetmeyen 52. madde hükmü, *tek suça* göre sorumluluk esasını kabul etmiş bulunmaktaydı¹²⁹⁸. Yine, 52. madde hükmünün uygulanması açısından gerçekleşen neticenin taksirle ya da muhtemel kastla gerçekleşmesi arasında bir fark gözetilmemektedir.

Ayrıca, dikkat edilmelidir ki; 52. madde hükmünün tatbiki için “*failin işlemeği kastettiği suçla gerçekleşen suç arasında nitelik farkının bulunmaması*” gerekir¹²⁹⁹; bir başka ifadeyle, “*işlenmesi istenen suçun hukuki konusu ile gerçekleşen suçun hukuki konusunun aynı olması şarttır*”¹³⁰⁰. Bu sonuç, 52. maddedeki “... *kastettiği şahıstan başka bir şahsın zararına ...*” ifadesinden çıkarılmaktay-

¹²⁹⁶ Aynı doğrultuda görüş için bkz. YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 326, 327. Yüce'ye göre, 52. madde hükmü özellikle hedefte sapma açısından “*olayın tabiatına uymayan bir düzenleme*”dir (YÜCE, Ceza Hukuku, sh. 428).

¹²⁹⁷ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 452: “Yanılma veya sapma sonucu istenilenden başka şahıs veya eşya üzerinde neticenin meydana gelmiş olması durumunda suç *tektir* ve tamamlanmıştır”.

¹²⁹⁸ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1057; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 355.

¹²⁹⁹ DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1058.

¹³⁰⁰ ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 356.

dı¹³⁰¹. Aksi takdirde, doktrinde bizim yukarıda izah ettiğimiz çözüm şekline göre meselenin halledilmesi gerektiği savunulmaktaydı^{1302, 1303}.

Hedefte sapma ile ilgili olarak yeni TCK'nın 44. maddesinin **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir¹³⁰⁴:

“Gerek doktrinde gerek uygulamamızda, hedefte sapma durumunda da fıkri içtima hükmünün uygulanması gerektiği konusundaki görüş hâkimdir. Bu nedenle, kanuni düzenlemede hedefte sapmanın şahısta yanılma ile birlikte değerlendirilmesinden vazgeçilmiştir. Örneğin bir kişiyi yaralamak için fırlatılan sopa, mağduru yaraladıktan sonra veya mağdura isabet etmeden vitrin camına çarparak kırılmasına neden olabilir. Bu durumda, sopa fırlatma fiiliyle hem tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış kasten yaralama suçu hem de başkasının malına zarar verme suçu işlenmiş olmaktadır. Aynı şekilde, bir kişiyi öldürmek için ateşlenen silahtan çıkan kurşun, mağdura isabet etmeden duvara çarpması nedeniyle sekerek bir başkasının ölümüne veya yaralanmasına neden olabilir. Bu durumda, hedeflenen kişi açısından kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır; ancak, sekme sonucunda ölümüne veya yaralanmasına neden olunan kişi açısından ise, taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu işlenmiş olmaktadır. Bu gibi durumlarda kişi işlediği bir fiille birden fazla farklı suçun oluşumuna neden olmaktadır ve bu suçlardan en ağır cezayı gerektireni ile cezalandırılmasıyla yetinilmelidir.”^{1305,1306}

¹³⁰¹ Ancak, Dömezer/Erman, buna rağmen, 52. madde hükmünün “suçun konusunda görülen yanılma ve inhiraf hallerini de kapsamına alacak şekilde” geniş yorumlanması gerektiği fikrindedirler: DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1059. Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Süleyman Arslan Armağanı, sh. 353 vd.; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/ MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 278 vd.

¹³⁰² DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1058. Ancak, Dömezer/Erman, bu durumda failin cezasının gerçek içtima kurallarına göre tayin edilmesi gerektiği fikrindedirler. Fakat, Yargıtay, A'nın B'ye vurmak maksadıyla attığı odunun cama isabet ederek kırılmasına sebebiyet vermesi hâdisesinde; A'nın nası ızzar suçundan dolayı da ayrıca mahkûm edilmesini hukuka aykırı bulmuştur: 6. CD., 18.5.1983, 1201/4611 (Çağlayan, Muhtar: Türk Ceza Kanunu, cilt IV, 3. bası, Ankara, tarih yok, sh. 668).

Keza, Yargıtay, “alacak meselesinden çıkan tartışmada S'nin eline geçirdiği çekici şoför koltuğunda oturan M'yi hedef alarak yaralamak kastıyla fırlattığı, T'nin M'yi geri çekmesi sonucu çekicinin M yerine aracın camına çarparak kırılmasına sebep olduğu (olayda); S'nin kastının ızzar olmayıp, yaralamak olduğu ve yaralamaya tam teşebbüsten hüküm kurulması gerekirken; manevî unsuru gerçekleşmeyen ve olayda uygulama yeri bulunmayan TCK'nın 79, 516/ilk madde ile hüküm kurulması(nın) bozmayı gerektir”diği içtihadında bulunmuştur: 8. CD., 10.4.1990, 2913/3591 (Savaş/Mollamahmutoğlu IV, sh. 5425).

¹³⁰³ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Süleyman Arslan Armağanı, sh. 353 vd.; İÇEL/ SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 278 vd.

¹³⁰⁴ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 452.

¹³⁰⁵ Öztürk/Ertem, yeni TCK'da hedefte sapma ile ilgili olarak 765 s. Kanunda olduğu gibi özel bir hükmün bulunmamasını eleştirmektedirler. Ancak, bu eleştirinin devamı olarak yaptıkları

açıklamalarda, madde gerekçesini teyid eden ifadeler kullanmaktadırlar (ÖZTÜRK/ERDEM, 9. bası, sh. 213 vd.). *Öztürk/Erdem*'in, bu bağlamda yaptıkları bazı açıklamalarda tutarsızlık bulunmaktadır: “*Failin hedef aldığı konu yanında bir başka konu üzerinde de suçun gerçekleşmesi durumunda, gerçekleşen netice sayısı kadar suçun bulunduğu sonucuna varılmalıdır. Böyle bir durumda birden fazla ihlal tek fiille gerçekleştirilmiş olmayacağı için fikri içtimadan da söz edilemez.*” (ÖZTÜRK/ERDEM, 9. bası, sh. 214). Aşağıda “çift neticeli sapma” ile ilgili olarak yaptığımız açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, *Öztürk/Erdem*'in bu açıklamalarının doğru olmadığı anlaşılabilmektedir.

¹³⁰⁶ 765 s (mülga) TCK'nın 52. maddesi hükmünün uygulanmasına ilişkin Yargıtay'ın şu kararları örnek gösterilebilir:

«S, karısını yaralamak amacıyla salladığı bıçakla araya giren oğlunu yaralamış bulunmaktadır. TCK'nın 52. maddesi sarahatına göre; cürümden zarar gören kimsenin sıfatından neş'et eden ve cezayı şiddetlendiren sebepler faille tahmil olunamayacağından; tayin edilen cezanın, yaralamak suçunu oğluna karşı işlemiş olmasından dolayı, TCK'nın 450. maddesinin 1. bendi delâletiyle 457. maddenin 2. fıkrasının uygulanması suretiyle arttırılması sözkonusu olamayacağı gibi; ancak tahfif sebebi mevcut olan ahvalde cürmün kasdolunan şahsa karşı işlendiğinin kabulü gerektiği cihetle; olayımızda olduğu gibi, şiddet sebebinin mevzuu bahis olduğu hallerde bu hükmeye istinad edilemeyeceği ve fiile dönüşmeyen kasıttan dolayı failin sorumlu tutulamayacağı gözönünde tutularak; karısı yerine oğlunu yaralamak şeklindeki fiilinden dolayı tayin edilen cezanın sadece suçun bıçakla işlenmesi nedeniyle TCK'nın 457. maddesinin 1. fıkrası uyarınca arttırılmasıyla yetinilmesi gerekirken; ayrıca akrabalık yönünden de aynı maddeye tevfikân artırma yapılması bozmayı gerektirmiştir». 2.CD, 3.4.1991, 3081/3865 (Erdurak[3], sh. 128/129).

«S'nin babasına attığı piknik tüpünün araya giren annesine değerek onun yaralanmasına sebep olmasına ve S'nin annesini yaralama kasdı bulunmamasına göre; fiiline TCK'nın 52. maddesi uygulanmalı (ve bu nedenle); müessir fiilden dolayı verilecek ceza 457. madde ile arttırılmamalıdır». 4.CD, 21.9.1988, 4755/5557 (YKD, Eylül 1989, sh. 1330).

«S'nin ağabeyi F ile H'nin kavga etmekte oldukları sırada S'nin elinde balta olduğu halde olay yerine geldiği ve ağabeyi ile kavga eden H'ya vurmak isterken H'nin çekilmesi nedeniyle baltanın ağabeyi F'nin başına isabetle yaralandığı anlaşılmış olmakla; S'nin fiilinin TCK'nın 52. maddesi delâletiyle değerlendirilmesi gerekir». 2.CD, 8.4.1993, 3376/4345 (Erdurak[3], sh. 129).

«S'nin eşine salladığı bıçağın ayırmak için araya giren kızına hata sonucu isabet ederek ... yaralanması olayında; TCK'nın 52. maddesi delâletiyle 456. maddenin 4. fıkrası ve (ayrıca,) suçun bıçakla işlenmiş olması nedeniyle, 457. maddenin 1. fıkrasının uygulanması suretiyle ceza tayini» gerekir». 2. CD, 21.10.1992, 9150/9830 (Erdurak[3], sh. 129).

«S, kardeşine vurmak isterken annesini yaralamış olmasına göre; TCK'nın 52. maddesi hükmü gereğince, yaralamayı kastettiği kişinin sıfatından doğan ağırlaştırıcı neden (faile) uygulanmaz: 4.CD, 16.10.1991, 4855/6038 (Erdurak[3], sh. 128).

Aralarında «... çıkan tartışmada A'nın 5-7 metreden B'ye attığı taşın, tarafları ayırmaya gelen Y'ye isabet ederek ölümüne neden olduğunun anlaşılması karşısında; A'nın fiilinin, müessir fiilde bulunmak kastıyla yaptığı fiille ölümüne neden olma şeklinde nitelendirilerek; TCK'nın 52. maddesi delâletiyle 452/1, 51/1. maddelerinin uygulanması suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesi» gerekir: 1.CD, 26.5.1993, 1044/1217 (Erdurak, Yılmaz Güngör, *Türk Ceza Kanunu*, 3. bası, Ankara, Ocak-1994, sh. 129 ve 812). «... (G)elişen kavgada sanıklardan R ile babası maktul M bir tarafta, diğer sanıklar H, K, A ve E karşı tarafta olmak üzere vuruşmaya başla(mışlardır. S)anıklardan H ve K'nın ve H'nin karısı E ve kayınvalidesi A'nın maktule karşı toplu halde saldırıları karşısında; (R,) babası maktulü bu toplu saldırıdan kurtarmak amacı ile elindeki keseri saldırganlardan H'ya vurmak isterken; (keserin) saldırı altında bulunan babası maktul M'nin başına (isabet etmesiyle vaki ölüm,) *hedefte hata* sonucu» meydana gelmiştir: 1. CD., 19.12.1979, 4873/4821 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh.748).

Hedefte sapma halinde, ika edilen fiil, tek bir fiil olmakla birlikte; işlenen bu fiil ile birden fazla suçun oluşumuna sebep olunmuştur. Bu itibarla, cezai sorumluluğa ilişkin çözüm şekli, yeni TCK'nın 43 ve 44. maddeleri hükümleri karşısında, her bir olayın mahiyetine göre farklılık arzedecektir.

Ancak, hedeflenen kişi dışında başka bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olunmuştur. İşlediği fiil sonucunda başka bir kişinin ölmesi veya yaralanması açısından failin kast veya taksirine göre, kasten veya taksirle öldürme veya yaralama suçu oluşmuştur. Fail, belli bir şahsı hedef alarak silahla ateş ederken veya bir cisim fırlatırken, silahtan çıkan kurşunun veya fırlattığı cismin hedef aldığı şahsın yanında bulunan bir başkasına isabet ederek onun ölümüne veya yaralanmasına neden olabileceğini muhtemel addettiği durumlarda, bu kişi açısından (olası) kastla işlenmiş öldürme veya yaralama suçu söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda, aynı veya farklı neviden fikrî içtima hükümlerinin uygulanmasıyla sorunun çözülmesi gerekmektedir.

Bu çözüm şekline göre şu ihtimaller söz konusu olabilir:

Tek neticeli hedefte sapma halleri:

Birinci ihtimal: A'nın B'yi yaralamak kastıyla fırlattığı cisim, B'ye isabet etmez ve fakat, hemen yanındaki otomobilin camına isabet ederek kırılmasına sebep olur.

Bu ihtimalde, A'nın B'ye karşı işlediği **kasten yaralama suçu teşebbüs** aşamasında kalmıştır. Keza, bu fiil ile A, B'nin hemen yanında bulunan otomobilin camını kırmakla, otomobil sahibine karşı olası kastla **mala zarar verme suçunu** işlemiş olur. **Farklı neviden fikri içtimanın** söz konusu olduğu bu durumda, TCK, m. 44 hükümleri gereğince somut olayda bu suçlardan hangisi daha ağır cezayı gerektiriyorsa bu suçtan dolayı mahkumiyet hükmü kurmak gerekir.

İkinci ihtimal: A'nın B'yi öldürmek kastıyla ateşlediği silahtan çıkan mermi çekirdeği, B'ye değil, hemen yanındaki C'ye isabet eder ve C ölür.

Bu ihtimalde, A'nın B'ye karşı işlediği **kasten öldürme suçu teşebbüs** aşamasında kalmıştır. A'nın silahından çıkan mermi çekirdeği, B'nin hemen yanında bulunan C'ye isabet etmiş ve C ölmüştür. Bu durumda A, aynı zamanda C'ye karşı **tamamlanmış kasten** (olası kastla) **öldürme suçunu** işlemiş olur. **Aynı neviden fikri içtima** hükümlerinin istisnalarından birini oluşturan bu durumda (TCK, m. 43, f. 2, 3), A hakkında **gerçek içtima** hükümlerine göre hem B'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten (doğrudan kastla) öldürme suçundan hem de C'ye karşı tamamlanmış kasten (olası kastla) öldürme suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekir^{1307,1308,1309}.

¹³⁰⁷ I. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 10.12.2013 tarihli ve E. 2012/1-1572, K. 2013/600 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Ercan, öldürmek kastıyla Ergün'ü hedef alarak silahını ateşler. Ancak, bu atışlardan Ergün'ün yakınında bulunan eşi Laika isabet alır ve yaralanır.

II. İlk derece mahkemesi bu olayda Ercan hakkında **kasten öldürme suçuna teşebbüsten** dolayı TCK, m. 81, f. 1; m. 35, f. 2 ... hükümlerine istinaden 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetmiştir (Ünye Ağır CM, 18.03.2008, 321-52).

III. Söz konusu mahkumiyet hükmünün temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, aşağıdaki gerekçe ile bozma kararı vermiştir (25.10.2010, 586-6893):

TCK'nın "44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima kurallarının uygulanmasını gerektiren farklı suçların oluşması koşulu gerçekleşmediğinden, **gerçek içtima** kurallarına göre hüküm kurulması gerektiği olayda," Ercan'ın;

a) mağdur Ergün'e yönelik fiil nedeniyle kardeşe karşı işlenmiş **kasten öldürme suçuna teşebbüsten** dolayı TCK, m. 82, f. 1, bent d; m. 35 ... hükümleri uyarınca;

b) mağdure Laika'ya yönelik fiil nedeniyle, **tamamlanmış kasten yaralama** suçundan dolayı TCK, m. 86, f. 1, f. 3, bent e; m. 87, f. 1, bent d; m. 21, f. 2... hükümleri uyarınca;

ayrı ayrı cezalandırılması gerekir.

IV. İlk derece mahkemesi bu bozma kararına uyarak yaptığı yargılama sonucunda, Ercan'ın;

a) mağdur Ergün'e yönelik olarak **kasten öldürme suçuna teşebbüsten** dolayı TCK, m. 82, f. 1, bent d; m. 35, f. 2 ... hükümleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile,

b) Laika'ya yönelik olarak, **olası kastla yaralama** suçundan dolayı TCK, m. 86, f. 1; m. 86, f. 3 bent e; m. 87, f. 1 (bent d ve son cümle); m. 21, f. 2 ... hükümleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile,

gerçek içtima hükümlerine göre ayrı ayrı cezalandırılmasına hükmetmiştir (25.02.2011, 344-38).

V. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu hükmün onanmasına karar vermiştir (13.02.2012, 7548-699).

VI. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise, söz konusu Özel Daire onama kararına aşağıdaki gerekçe ile itiraz etmiştir (23.03.2012, 175104).

"Sanığın fiili, hareketin tek olması nedeniyle tektir. Eylemi nedeniyle Ergün'e yönelik kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs ve Laika'ya yönelik olası kastla yaralama suçları oluşmuştur. Öldürme ve yaralama suçları farklı suçlardır. Bu nedenle olayda aynı neviden (fikri) içtima (hükümlerinin), başka bir anlatımla TCK'nın 43/2-3 maddesinin uygulama olanağı bulunmamaktadır. Oluşan suçların farklı olması nedeniyle TCK'nın 44. maddesinde yer alan fikri içtima kurallarının uygulanması gündeme gelecek ve sanığın bu suçlardan somut olaya göre en ağırlı olan kardeşini öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerekecektir. Kanun koyucunun TCK'nın 43/3. maddesinde bilerek koyduğu düzenlemenin bir benzerini TCK'nın 44. maddesinde yapmamasının sonucunu sanığa yüklemek adil de olmayacaktır. Anılan değerlendirmelerin ışığında, sanık Ercan hakkında TCK'nın 44. maddesi uyarınca **farklı neviden fikri içtima** kuralları uygulanarak en ağır olan kardeşini öldürmeye teşebbüs suçu nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmesi gerekir".

VII. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu itirazını aşağıdaki gerekçe ile reddetmiştir:

"5237 sayılı TCK'nın hazırlanmasında esas alınan suç teorisine göre, suçun maddi unsurları arasında yer alan suçun konusu, kanunda tanımlanan tipik hareketin üzerinde icra edildiği kişi ya da şey olarak açıklanmaktadır.

Hedefte sapma; yapılan hareketin, gerçekleştirilmek istenen suç konusu üzerinde değil de failin yetersizliği veya yeteneğini gereği gibi kullanamaması ya da sair bir sebepten ötürü meydana gelen sapma sonucunda başka bir konu üzerinde gerçekleşmesidir. Hedefte sapma hâlinde bir hata söz konusu değildir. Zira, hedefte sapmada sapan failin iradesi değil hareketidir. Bu halde hareket adeta saparak yön değiştirmekte ve neticesini istenilen konu üzerinde değil de başka bir konu ya da istenilen konu yanında istenilmeyen başka konu veya konular üzerinde gerçekleştirilmektedir. Hatada ise failin bilgisizliği ya da yanlış bilgisi söz konusu olup, failin düşündüğü ile

gerçek arasında zıtlık bulunmaktadır. Bu itibarla, hedefte sapma ile hatanın özel bir hali olan şahısta hata farklı hususlardır. Şahısta hatada fail mağdurun şahsında hataya düşmektedir. Örneğin, failin A'yı öldürmek isterken, A olduğunu zannederek B'yi öldürmesi gibi. Oysa hedefte sapmada fail, eylemini gerçekleştirmek istediği kişiyi karıştırmamakta, ancak hareketinin sonucunda meydana gelen sapma nedeniyle kastettiği kişi dışında bir başka kişi veya kastettiği kişiyle birlikte başka bir kişiyi de öldürmekte ya da yaralamaktadır.

765 sayılı TCK'nda hedefte sapma, şahısta hata hali ile birlikte 52. maddesinde; "Bir kimse bir hata veya sair bir arıza yüzünden cürmü kast ettiği şahıstan başka bir şahsın zararına işlemiş olursa cürmünden zarar gören kimsenin sıfatından neşet eden ve cezayı şiddetlendiren esbap faile tahmil olunmaz. Belki cürüm kast olunan şahsa karşı işlenmiş gibi telâkki olunarak, fail cürmün tazammun edebileceği esbabı muhaffefeden istifade eder" şeklinde düzenlenmiştir.

5237 sayılı TCK'nda ise hedefte sapma haline ilişkin özel bir hüküm bulunmadığından hedefte sapma halinde failin sorumluluğunun, meydana gelen netice bakımından failin kusurunun ne olduğu ile suçların içtimai kuralları çerçevesinde çözümlenmesi gerekmektedir. Nitekim, hata konusunun düzenlendiği 30. maddenin gerekçesinde, "Hedefte sapma hali ile ilgili olarak bu madde kapsamında düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir. Çünkü hedefte sapma halinde bir hata söz konusu değildir. Bu durumda suçların içtimai hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gereken bir sorun söz konusudur. Nitekim uygulamada da hedefte sapma, suçların içtimai ve özellikle fikri içtima kapsamında ele alınmaktadır" denilmiştir.

5237 sayılı TCK'nın hazırlanmasında "kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır" ilkesi esas alınmış, dolayısıyla da gerçek içtima kuralı benimsenmiştir. Nitekim Adalet Komisyonu raporunda bu husus; "Ceza hukukunun temel kurallarından birisi, 'kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır' şeklinde ifade edilmektedir. Bunun istisnaları, suçların içtimai bölümünde belirlenmiştir. Bu istisnalar dışında, işlenen her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir. Böylece verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır" şeklinde ifade edilmiştir (TBMM Adalet Komisyonu'nun 03.08.2004 gün ve 1/593-60 sayılı Raporu). Bu kuralın istisnalarına ise, 5237 sayılı TCK'nın "suçların içtimai" bölümünde, 42 (bileşik suç), 43 (zincirleme suç) ve 44. (fikri içtima) maddelerinde yer verilmiştir.

765 sayılı TCK'nda, aynı nev'iden fikri içtima ile farklı nev'iden fikri içtima tek madde halinde 79. maddede düzenlenmiş iken, 5237 sayılı TCK'nda bu iki hal birbirinden ayrılarak, aynı nev'iden fikri içtima, zincirleme suçun düzenlendiği 43. maddenin 2. fıkrasında, farklı nev'iden fikri içtima ise kanunun 44. maddesinde düzenlenmiştir.

5237 sayılı TCK'nın "Zincirleme Suç" başlıklı 43. maddesinin 2. fıkrasında; "Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır" denilmek suretiyle zincirleme suçtan farklı bir müessese olan aynı nev'iden fikri içtima düzenlenmiş, tek fiil (hareket) ile aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi durumunda, hareketin sayısı nedeniyle, fail hakkında bir cezaya hükmolunacağı, ancak bu cezanın TCK'nın 43/1. maddesine göre artırılacağı öngörülmüştür.

TCK'nın 43. maddesinin 3. fıkrasında ise; "Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz" hükmüne yer verilmek suretiyle, bu suçlarda zincirleme suç hükümleri ile aynı nev'iden fikri içtima kuralının uygulanmayacağı, dolayısıyla sayılan bu suçlarda, failin mağdur sayısının ayrı ayrı cezalandırılacağı kabul edilmiştir.

Yine 5237 sayılı TCK'nda yaptırma bağlanan bazı suçlarda, özel olarak aynı nev'iden fikri içtima hükmüne yer verilmesi suretiyle, bu suçlarda ayrıca TCK'nın 43/2. maddesi uyarınca cezanın arttırılmayacağı esası benimsenmiştir. Örneğin; TCK'nın 172. maddesinin 2. fıkrasında; belirsiz sayıda kişilerin sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutulması halinde, radyasyon yayma suçunun temel şekline nazaran daha ağır ceza öngörülmüştür.

Bu açıklamalara göre, aynı nev'iden fikri içtimanın şartlarını, hareket ya da fiilin hukuki anlamda tek olması, tek fiille birden fazla aynı suçun işlenmiş olması, suç mağdurlarının farklı olması, işlenen suçun 5237 sayılı TCK'nın 43. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen suçlardan olmaması, suç tipinde özel olarak aynı nev'iden fikri içtima hükmüne yer verilmemesi şeklinde belirlemek mümkündür.

Farklı neviden fikri içtima ise 5237 sayılı Kanunun 44. maddesinde; "(1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezaı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır" şeklinde düzenlenmiş olup, bu hükmün uygulanabilmesi için işlenen bir fiille birden fazla farklı suçun oluşması gerekmektedir.

Kanun koyucu, işlediği bir fiille birden fazla farklı suçı işleyen failin, fiilinin tek olması nedeniyle en ağır ceza ile cezalandırılmasını yeterli görmüş, bu şekilde "non bis in idem" kuralı gereğince bir fiilden dolayı kişinin birden fazla cezalandırılmasının da önüne geçilmesini amaçlamış, "erime sistemi"ni benimsemek suretiyle, bu suçlardan en ağır cezaı gerektiren suçtan dolayı ceza verilmesi ile yetinilmesini tercih etmiştir.

Farklı neviden fikri içtima kuralları da şartlarının bulunması halinde kural olarak her suç için uygulanabilir ise de, kanun koyucunun açıkça istisna öngördüğü hallerde bu kuralın uygulanması imkanı bulunmamaktadır. Nitekim, 5237 sayılı TCK'nın 212. maddesinde, sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunacağı belirtilerek, açıkça fikri içtima hükümlerinin uygulanması engellenmiştir.

Bu anlatıma göre de, farklı neviden fikri içtimanın şartları da, hareket ya da fiilin hukuki anlamda tek olması, tek fiille birden fazla farklı suçun işlenmiş olması, işlenen suçlarla ilgili kanunda açıkça fikri içtima hükümlerinin uygulanmasının engellenmemiş olması şeklinde belirlenebilecektir.

Görüldüğü gibi; 5237 sayılı TCK'nın gerek 43. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen aynı neviden fikri içtima, gerekse 44. maddesinde hüküm altına alınan farklı neviden fikri içtimada hukuki anlamda tek bir fiille birden fazla suçun işlenmesi söz konusudur. Bununla birlikte aynı neviden fikri içtimada suçlar aynı iken, farklı neviden fikri içtimada suçların farklı olması hususu iki düzenleme arasındaki ayrımı ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda, "aynı suç" ile "farklı suç" kavramlarının ve 5237 sayılı TCK'nın 44. maddesinde yer alan "bir fiil" ibaresi ve aynı kanunun 43. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "tek bir fiil" ifadesi ile kast edilen hususun ne olduğunun da açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

5237 sayılı TCK'nın 44. maddesinin gerekçesinde; "Bir suçun temel ve nitelikli şekilleri dışındaki suçlar, fikri içtima uygulamasında farklı suç olarak kabul edilmelidir" şeklinde açıklamaya yer verildiğinden, buna göre, anılan maddede yer alan "farklı suç"tan kastedilen, bir suçun temel ve nitelikli şekilleri dışında kalan ve Türk Ceza Kanununda ya da özel ceza kanunlarında yer alan, yani ceza hukuku mevzuatındaki diğer suç hükümleridir. Bunun yanında, bir suçun basit hali ile nitelikli hali ya da unsurları aynı olan suçlar aynı suç sayılacağı gibi, bir suçun teşebbüs halinde kalması ile tamamlanması veya olası kastla işlenmesi ile doğrudan kastla işlenmesi hallerinde de aynı suç söz konusu olacaktır.

Bu bağlamda uyumsuzluk konusu ile bağlantılı olarak, TCK'nın "Hayata karşı suçlar" bölümünde 81 ve 82. maddelerinde hüküm altına alınan "kasten öldürme" ve "kasten nitelikli öldürme" suçları ile "Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar" bölümünde 86 ve 87. maddelerinde tanımlanan "kasten yaralama" ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının farklı suçlar olduğu rahatlıkla söylenebilecektir.

TCK'nın 43. maddesinin üçüncü fıkrasında aynı nev'iden fikri içtimanın uygulanamayacağı suçlar arasında "kasten öldürme" sayılmışken, 44. maddede düzenlenen farklı nev'iden fikri içtima ile ilgili olarak kasten öldürme suçları yönünden böyle bir istisnaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla, TCK'nın 43/3. maddesinde sayılan suçlar tek fiille birden çok kişiye karşı işlendiği takdir-

de gerçek içtima kuralı uygulanacak, her bir suçtan dolayı fail ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Fakat söz konusu istisnaya kanunun 44. maddesinde yer verilmediğinden, aynı fiille 43. maddenin 3. fıkrasında sayılan suçlarla birlikte bir başka suçun işlenmesi halinde, farklı neviden fikri içtima hükümleri gereğince en ağır suçtan ceza verilecektir. Diğer bir deyişle, hukuki anlamda tek bir fiille bir kişinin kasten öldürülmesi yanında, başka bir suçun da işlendiği durumlarda, öncelikle ikinci suçun nitelendirilmesi yapılacak, ikinci suçun kasten öldürme suçu ile aynı suç olduğunun saptanması halinde aynı neviden fikri içtima hükümleri değil, TCK'nın 43/3 maddesi göz önüne alınarak gerçek içtima kuralları uygulanacak, ikinci suçun kasten öldürme suçundan farklı bir suç olduğunun belirlenmesi halinde ise 44. maddede düzenlenen farklı nev'iden fikri içtima kuralı uyarınca sadece cezası en ağır olan suçtan ceza verilmesi ile yetinilecektir.

...

Doğal anlamda gerçekleştirilen her bedeni hareket ayrı bir eylemi oluşturmakta ise de, hukuki anlamda hareketin tek olması ile ifade edilmek istenen husus, doğal anlamda birden fazla hareket bulunsu dahi, bu hareketlerin, hukuki nedenlerden dolayı değerlendirmede birlik oluşturması suretiyle tek fiil olarak kabulüdür. Diğer bir anlatımla, doğal anlamda fiilin tek olduğu her halde hukuki anlamda da fiilin tek fiil olarak olduğu söylenebilirse de, doğal anlamda fiilin çok olduğu her halde hukuki anlamda da fiilin çok olduğu her zaman söylenemeyecektir. Bazen bir hareketler kümesi, hukuki açıdan tek bir fiil olarak kabul edilecektir. Bu halde suç tipinin birden fazla hareketle ihlal edilmiş olması hareketin hukuken tek olmasını etkilemeyecek, doğal hareketler hukuken tek kabul edilecektir. Fikri içtimada da, fiil ya da hareketin tekliliği, doğal anlamda değil hukuki anlamda tek olmayı ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak bir kısım suçların işlenmesi sırasında doğal olarak birden fazla hareket yapılmakta ise de, ortaya konulan bu davranışlar suçun kanuni tanımında yer alan hukuksal anlamdaki "tek bir fiili" oluşturmaktadır.

... Doğal anlamda birden fazla hareketin hukuki anlamda tek bir fiil olarak kabul edilip edilemeyeceği işlenen suçun özelliği de gözönüne alınarak yapılacak hukuki değerlendirme sonucunda belirlenmelidir. Bu bakımdan korunan hukuki menfaatler arasında en üstte yer alan yaşam hakkı ve vücut dokunulmazlığına yönelik eylemlerde eğer fail doğal anlamda birden fazla hareketle bir ya da birkaç kişiyi öldürmek ya da yaralamak amacıyla, öldürmek ya da yaralamak istediği kişinin yanında veya yakınında bulunan başka kişilerin de ölebileceğini veya yaralanabileceğini öngörmesine rağmen bunu göze alarak hareket ediyorsa artık ortada tek bir fiil değil, mağdur sayısınca birden çok fiil bulunduğunu kabul etmek gerekir. Ancak bunun için failin doğrudan ya da olası kastla hareket ettiğinin belirlenmesi gereklidir.

Bu açıklamalar ışığında uyumsuzluk konusu değerlendirildiğinde;

Söz konusu "olayda, kardeşini öldürmek amacıyla iki el ateş eden sanığın kardeşinin hemen yakınında bulunan yengesinin de ölebileceğini ya da yaralanabileceğini öngörmesine karşın, bunu göze alarak birden çok kez ateş etmesi eyleminin suçla korunan hukuki menfaatler göz önünde bulundurulduğunda hukuki anlamda tek fiil sayılması mümkün olmayıp, TCK'nın 44. maddesinin uygulanma şartları oluşmamıştır.

Bu nedenle, sanığın katılan Ergün'e yönelik kasten öldürme suçuna teşebbüs ve Laika'ya yönelik olası kastla yaralama eylemlerinden ayrı ayrı cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme hükmü ile bu hükmü onayan Özel Dairenin kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır."

Hukuki değerlendirmelerimiz:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararı, hedefte sapma ve bu bağlamda içtima konusunun en ayrıntılı bir şekilde ele alınıp değerlendirildiği bir karar özelliğini taşımaktadır.

Kararda belirtildiği üzere, tek bir fiil ile bir kişinin öldürülmesinin yanı sıra, örneğin mala zarar verilmiş olması halinde, gerçek içtima hükümlerine göre her bir suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilmeyecek; farklı neviden içtima hükümlerine göre bu suçlardan daha ağır cezayı gerektiren kasten öldürme suçundan dolayı cezaya hükmedilecektir.

Buna karşılık, A'nın B'yi öldürmek kastıyla ateşlediği silahtan çıkan mermi çekirdeği, B'ye değil, duvara çarpıp sekmesi sonucunda C'ye isabet eder ve C ölürse, bu kişiye karşı işlenen suç, **taksirle ölüme sebebiyet verme suçu** olur.

Ancak bu açıklamaya rağmen, Kararda tek bir fiil ile bir kişinin öldürülmesi ve bir başka kişinin yaralanması halinde, doğru olmayan bir gerekçeyle doğru olan bir sonuca ulaşılmıştır. Şöyle bir örnekte konuyu açıklamaya çalışalım: Örneğin, silahla yapılan atışla A isabet alarak ölür ve B ise yaralanır. Ceza Genel Kurulu, söz konusu kararında, bu durumda bir kişi ölmüş ve bir kişi de yaralanmış olduğu için, neticeden hareketle iki ayrı fiilin mevcut olduğunu kabul etmiş ve dolayısıyla, gerçek içtima hükümlerine göre, fail hakkında her iki suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilmesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

Oysa, yeni TCK'nın esas aldığı suç teorisinde, neticeden hareketle, fiil sayısını belirleme imkanı bulunmamaktadır. Fiil ve netice, suçun iki ayrı maddi unsurunu oluşturmaktadır. Yeni TCK'nın düzenlemelerinde terkedilmiş olan bu anlayış, klasik suç teorisinin günümüze yansımalarından ibarettir.

Söz konusu örnekte, esasında bir fiil ile A'ya karşı tamamlanmış kasten (doğrudan kastla) öldürme, B'ye karşı ise teşebbüs aşamasında kalmış kasten (olası kastla) öldürme suçu işlenmiştir. Bu durumda, TCK, m. 43, f. 3 hükmünü dikkate alarak, gerçek içtima hükümlerine göre her iki suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekecektir.

Bu bağlamda Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararı sonuç itibarıyla doğru ise de gerekçesi itibarıyla tutarsızdır.

¹³⁰⁸ Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 8.5.2017 tarihli ve E. 2017/115 K. 2017/1481 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; A, B ile kavga eder. A'nın kardeşi C, kavgayı ayırmak için aralarına girer. A, B'ye bıçak savurmaya başlar ve bunu birden çok defa tekrarlar. Bu sırada A'nın savurduğu bıçak, B'nin hemen yanında bulunan C'ye isabet eder ve C ölür. B ise, yaralanmaz.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu olayla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “B'ye bıçakla saldıran A'nın kavgayı ayırmak amacıyla aralarına giren ve mağdurun yanında bulunan C'nin ölebileceğini ya da yaralanabileceğini öngörmesine karşın, bunu göze alarak mağdura doğru birden çok bıçak savurma şeklindeki eyleminin **suçla korunan hukuki menfaatler göz önünde bulundurulduğunda hukuki anlamda tek fiil sayılması(nın) mümkün olma(dığı ve dolayısıyla, bu olayda), TCK'nın 44. maddesinin uygulanma şartları(nın) oluşmadığı ...**” yönünde içtihatla bulunmuştur.

Ceza, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin bir kararında da, klasik suç teorisinin etkisiyle, neticeyi esas alarak suç sayısını belirleme yoluna gidilmiştir:

“... **tek bir ateş etme eylemiyle hedef alınan kişinin yaralanması ile birlikte ayırmak için araya giren bir başka şahsın da yaralanması halinde dış dünyada tek hareketle iki değişiklik yani iki sonuç ve dolayısıyla iki fiil meydana gelmekle fikri içtimadan söz edilemeyeceği anlaşıl-makla, sanığın tartışma sırasında mağdur Kubilay Kılıç'ı yaralamak kastıyla ateş ettiği sırada kendilerini ayırmaya çalışan mağdur Erdoğan Ayas'ın yaralanabileceğini öngörmesine rağmen eylemini gerçekleştirmesi ve iki ayrı netice ve fiil oluşması ile bu durumun fikri içtima hükümleri kapsamına girmemesi sebebiyle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edil-memiş**”tir: Yargıtay 8. CD, 20.6.2012, E. 2009/18262, K. 2012/21120.

Kısaca belirtmek gerekir ki, sonuç itibarıyla doğru bulduğumuz bu içtihatlar, hukuki gerekçe-si itibarıyla sorunludur.

¹³⁰⁹ Yargıtay, mülga 765 s. TCK döneminde verdiği bir kararında, bu gibi durumlarda *farklı nevi-den fikri içtima* hükümlerinin uygulanması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştu:

«S'nin M'yi yaralamak amacıyla tabancasıyla yaptığı atış sonucu P'nin yaralanmış olmasına göre; TCK'nın 52 ve 79. maddeleri gözetilmeden; ayrıca M'yi yaralamaya teşebbüs suçundan da ceza tayini, bozmayı gerektirmiştir»: 4. CD, 21.9.1981 (Çağlayan, Muhtar: *Türk Ceza Ka-nunu*, cilt I, 3. bası, Ankara 1984, sh. 583).

Bu durumda, **farklı neviden fikri içtima** söz konusu olur ve A hakkında TCK, m. 44 hükümleri gereğince daha ağır cezayı gerektiren suç olması itibarıyla sadece B'ye karşı işlediği **teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürme suçun**dan dolayı mahkumiyet hükmü kurmak gerekir.

Üçüncü ihtimal: A'nın B'yi öldürmek kastıyla ateşlediği silahtan çıkan mermi çekirdeği, B'ye değil, hemen yanındaki C'ye isabet eder ve C yaralanır.

Bu ihtimalde de, A'nın B'ye karşı işlediği **kasten öldürme suçu teşebbüs** aşamasında kalmıştır. A'nın silahından çıkan mermi çekirdeği, B'nin hemen yanında bulunan C'ye isabet etmiş ve C yaralanmıştır. Bu durumda A, aynı zamanda C'ye karşı **teşebbüs aşamasında kalmış kasten** (olası kastla) **öldürme suçu**nu işlemiş olur. **Aynı neviden fikri içtima** hükümlerinin istisnalarından birini oluşturan bu durumda (TCK, m. 43, f. 2, 3), A hakkında **gerçek içtima** hükümlerine göre hem B'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten (doğrudan kastla) öldürme suçundan hem de C'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten (olası kastla) öldürme suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekir.

Buna karşılık, A'nın B'yi öldürmek kastıyla ateşlediği silahtan çıkan mermi çekirdeği, B'ye değil, duvara çarpıp sekmesi sonucunda C'ye isabet eder ve C yaralanır ise, bu kişiye karşı işlenen suç, **taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçu** olur. Bu durumda, **farklı neviden fikri içtima** söz konusu olur ve A hakkında, TCK, m. 44 hükümleri gereğince daha ağır cezayı gerektiren suç olması itibarıyla sadece B'ye karşı işlediği **teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürme suçundan** dolayı mahkumiyet hükmü kurmak gerekir.

Dördüncü ihtimal: A'nın B'yi yaralamak kastıyla fırlattığı taş, B'ye değil, hemen yanındaki C'ye isabet eder ve fakat, C ölür.

Bu ihtimalde de, A'nın B'ye karşı işlediği **kasten yaralama suçu teşebbüs** aşamasında kalmıştır. A'nın fırlattığı taş, B'nin hemen yanında bulunan C'nin başına isabet etmiş ve C ölmüştür. Bu durumda A, aynı zamanda C'ye karşı **neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten** (olası kastla) **yaralama suçu**nu işlemiş olur. **Aynı neviden fikri içtima** hükümlerinin istisnalarından birini oluşturan bu durumda (TCK, m. 43, f. 2, 3), A hakkında **gerçek içtima** hükümlerine göre hem B'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten (doğrudan kastla) yaralama suçundan hem de C'ye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten (olası kastla) yaralama suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekir.

Beşinci ihtimal: A, B'ye zarar vermek kastıyla hareket halindeki otomobiline doğru taş fırlatır. Ancak, taş, B'nin otomobiline değil, C'nin park halindeki otomobiline isabet eder. Otomobilin camı kırılır.

Bu ihtimalde, A'nın B'ye karşı işlediği **mala zarar verme suçu teşebbüs** aşamasında kalmıştır. Keza, bu fiil ile A, otomobilinin camını kırmakla, C'ye karşı da olası kastla **mala zarar verme suçu**nu işlemiş olur. **Aynı neviden fikri iç-**

timain söz konusu olduğu bu durumda, TCK, m. 43, f. 2 ve bu fıkra da atıfda bulunulan f. 1 hükümleri gereğince somut olayda bu suçlardan hangisi daha ağır cezayı gerektiriyorsa bu suçtan dolayı verilecek ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar belirlenecek bir oranda artırılır.

Altıncı ihtimal: A, kendisine hakaret eden B'yi yaralamak kastıyla elindeki sopayı fırlatır. Ancak, sopa C'ye isabet eder ve C yaralanır.

Bu ihtimalde, biri teşebbüs aşamasında kalmış kasten yaralama suçu, diğeri ise tamamlanmış kasten (olası kastla) yaralama suçu olmak üzere iki suç işlenmiştir. Her iki suçtan dolayı **gerçek ictima** hükümlerine göre cezalandırılması gereken A hakkında **bu suçlardan sadece B'ye karşı işlenen ve teşebbüs aşamasında kalan suçla ilgili olarak haksız tahrik hükümleri uygulanabilir**^{1310 1311}.

Yedinci ihtimal: Meşru savunma halinde olan A, saldırısını etkisiz kılmak amacıyla B'ye silahla ateş ederse de, silahtan çıkan mermi çekirdeği B'ye değil, C'ye isabet eder. C ölür veya yaralanır.

Bu durumda meşru savunmada sınırın aşılmasıyla hedefte sapma hükümlerini birlikte değerlendirmek gerekir.

¹³¹⁰ ÖZGENÇ, Süleyman Arslan Armağanı, sh. 359.

¹³¹¹ «Sanıklardan Ali'nin kazlarını sanık Azmi'nin bahçesine soktuğu, bu yüzden çıkan tartışmada sanık Azmi'nin 5-7 metreden sanık Ali'ye attığı taşın, tarafları ayırmaya gelen Yusuf'a isabet ederek başta çökme kırığı husule getirip beyin kanamasından ölümüne neden olduğunun anlaşılması karşısında; sanık Azmi'nin fiilinin müessir fiilde bulunmak kastıyla yaptığı fiille ölümüne neden olma şeklinde nitelendirilerek, TCK'nın 52. maddesi delâletiyle 452/1, 51/1. maddelerinin uygulanması suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadırlar: 1. CD., 26.5.1993, 1044/1217 (Erdurak[3], sh. 812).

Olayda ölüm neticesi istenmiş değildir. Azmi taşı Ali'yi yaralamak için atmış; ancak taş, hedefte sapma sonucu, Yusuf'a isabet etmiş ve onun ölümüne neden olmuştur. Olayın cereyan şekli dikkate alındığında, Azmi'nin Ali'ye karşı yaralama kasdıyla hareket etmiş olduğu sonucuna ulaşılabilir. Azmi, Ali'yi öldürmek kasdıyla hareket etmemiştir. Bu itibarla, Ali'ye karşı işlenen kasten yaralama suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır ve Azmi'yi bu suçtan dolayı sorumlu tutmak gerekir.

Azmi'nin 5-7 metreden Ali'ye attığı taş, tarafları ayırmaya gelen Yusuf'a isabet ederek başta çökme kırığı husule getirip beyin kanamasından ölümüne neden olmuştur. Azmi, Ali'yi hedef alarak taş atarken, bu taşın kendilerini ayırmaya gelen Yusuf'a isabet edebileceğini müşahade etmiştir. Buna rağmen taşı atmıştır. Bu itibarla, Ali'yi hedef itti haz ederek yaralama kastıyla attığı taşın Yusuf'a isabet ederek onun yaralanmasına sebebiyet verebileceğini muhtemel addetmiştir. Yusuf'a karşı da olası (muhtemel) kastla işlenen yaralama neticesinde Yusuf ölmüştür. Bu durumda, Yusuf'un ölümü itibarıyla, olayda bir netice sebebiyle ağırlaşmış suç hali mevcuttur.

Netice olarak; bu olayda Azmi bir fiille hem **teşebbüs aşamasında kalmış kasden yaralama suçunu** (TCK, m. 86, f. 1, 3; m. 35) hem de **neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten** (olası kastla) **yaralama suçunu** (TCK, m. 87, f. 4; m. 21, f. 2) işlemiştir. TCK, m. 43, f. 3 hükmü karşısında Azmi'nin bu iki suçtan dolayı **gerçek ictima** hükümlerine istinaden cezalandırılması gerekmektedir.

Bu iki suçtan sadece Ali'ye karşı işlenen teşebbüs aşamasında kalmış kasten yaralama suçu ile ilgili olarak haksız tahrik hükümleri uygulanabilir.

A, maruz kaldığı saldırı karşısında, bu saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla savunma hareketi gerçekleştirmiştir. Bu durumda saldırı devam etmekte olup, henüz sona ermemiştir. Elinde silah bulunan saldırganla karşı karşıya bulunan kişinin korku, telaş ve heyecana kapılması, olağan bir durumdur. Kişinin maruz kaldığı bu saldırının kendisinde oluşturduğu korku, telaş ve heyecanın etkisiyle davranışlarını serbestçe yönlendirme yeteneğinden bahsedilemez. Bu korku, telaş ve heyecanın etkisiyle hareket eden kişinin gerçekleştirdiği savunma hareketinin saldırgan üzerinde değil de, saldırıyla ilgisi olmayan bir başkası üzerinde etki meydana getirmesi halinde de sorunun meşru savunmada sınırın aşılması hükümleri çerçevesinde değerlendirmek gerekir^{1312, 1313}.

¹³¹² Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 6.4.2011 tarihli ve E. 2010/6134, K. 2011/2092 sayılı kararına konu teşkil eden olayda; kolluk görevlileri, mahkemece verilmiş karara istinaden, Ankara İli Yenimahalle İlçesi Anadolu Bulvarı üzerinde önleyici mahiyette yol kontrolü yaparlar. Bu sırada M'nin sevk ve idaresindeki otomobil durdurulmak istenir. Ancak M, "dur" ihtarına rağmen durmaz. Bunun üzerine kolluk görevlileri H ve T, kaçan aracı motosikletle takip ederler, durması için sürücüyü uyarırlar, havaya birkaç kez uyarı ateşi yapmalarına rağmen aracı durduramazlar. T motosikletle aracın önüne geçmeye çalıştığı sırada, araç motosiklete çarpar. Bu çarpma sebebiyle motosiklet hasar görür ve H ve T, "basit derecede" yaralanırlar.

H, bu sırada yoldan geçmekte olan Y'nin kullandığı araca binerek onunla birlikte kaçan aracı takibe devam ederler. Bu takip sürecinde H, görev gereği taşıdığı tabanca ile hareket halindeki otomobile doğru arkadan 6 metre mesafeden birkaç el ateş eder. Bu atışlardan araca 6 adet mermi çekirdeği isabet eder. Mermi çekirdeklerinden biri, aracın arka koltuğunda oturmakta olan A'nın kafasına arkadan isabet ederek ölümüne sebep olur.

M'nin çocuk olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı anlaşılar.

İlk Derece Mahkemesi bu olayda H hakkında **olası kastla öldürme suçundan** dolayı TCK, m. 81; m. 21, f. 2 hükümlerine istinaden mahkumiyet hükmü kurmuştur.

Buna karşılık Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu olayda H hakkında "kasten yaralama sonucu ölüm neden olmak suçundan", yani **neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçundan** TCK, m. 87, f. 4, ikinci cümle hükmüne istinaden mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

Dairenin kararına göre, H, hukuka uygunluk nedeninde sınırı **kasten** aşmıştır. Ancak H **yaralama kastıyla** hareket ederken, "*istenmeyen ölüm sonucu*" meydana gelmiştir.

Keza, Daire kararına göre, ölümüne sebebiyet verilen kaçan M olmadığı için, olayda haksız tahrik hükümleri uygulanamaz.

Ayrıca, Daire'nin kararına göre, M, on sekiz yaşını bitirmemiş **çocuk** olduğu için, suçun olası kastla öldürme suçu olduğunun kabulü halinde, H hakkında TCK, m. 82, f. 1, bent e ve m. 21, f. 2 hükümlerine istinaden mahkumiyet hükmü kurulması gerekirdi.

Dairenin bu kararına iştirak etmek hukuken mümkün değildir. Öncelikle, "dur" ihtarına uymayan bu sürücünün başka suretlerle durdurulması ve yakalanması mümkün iken, seyir halindeki araç silahla hedef ittihaç edilerek müteaddit el ateş edilmesi halinde artık bir hukuka uygunluk sebebinin varlığından bahsedilemez. Olayın oluş seyri itibarıyla H'nin yaralama kastıyla hareket ettiği de söylenemez. H, silahla otomobili hedef ittihaç ederek yaptığı atışlar sırasında, araç içerisinde bulunan kişilerin de isabet alabileceğini, yaralanabileceğini ve hatta, ölebileceğini öngörmüştür. Buna rağmen silahla müteaddit el ateş etmekten imtina etmemiştir. Bu itibarla, İlk Derece Mahkemesinin kararında olduğu gibi, H'yi M'ye karşı **olası kastla** işlediği **kasten öldürme suçundan** dolayı sorumlu tutmak gerekirdi.

Çok neticeli hedefte sapma halleri:

Birinci ihtimal: A, öldürmek kastıyla otomobilin içinde bulunan B'ye silahıyla ateş eder. B ölür. Silahla yapılan atışlar sebebiyle otomobil hasar görür.

Bu durumda B'ye karşı işlenen suç, **kasten öldürme suçudur**. Keza aynı fiille, otomobil sahibine karşı **mala zarar verme suçu** işlenmiştir. **Farklı neviden fikri içtimaı**n söz konusu olduğu bu durumda, TCK, m. 44 hükümleri gereğince daha ağır cezayı gerektiren suç olması itibarıyla sadece B'ye karşı **kasten öldürme suçundan** dolayı mahkumiyet hükmü kurmak gerekir.

İkinci ihtimal: A, B'yi öldürmek kastıyla silahıyla birkaç el ateş eder. Silahtan çıkan mermi çekirdeklerinden biri B'ye isabet eder ve B ölür. Mermi çekirdeklerinden diğeri ise hemen yanındaki C'ye isabet eder ve C de ölür.

Bu durumda B'ye karşı işlenen suç, **kasten öldürme suçudur**. Keza aynı atışlardan çıkan mermi çekirdeklerinden diğeri B'nin hemen yanında bulunan C'ye isabet eder ve C ölür. Bu durumda ikinci suç olarak A'nın C'ye karşı işlediği suç, **kasten (olası kastla) öldürme suçudur**. **Aynı neviden fikri içtima** hükümlerinin istisnalarından birini oluşturan bu durumda (TCK, m. 43, f. 2, 3), A hakkında **gerçek içtima** hükümlerine göre hem B'ye karşı kasten (doğrudan kastla) öldürme suçundan, hem de C'ye karşı kasten (olası kastla) öldürme suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekir¹³¹⁴.

¹³¹³ Bu konuda farklı değerlendirme için bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler, 11. bası, sh. 283, 305. İlginçtir ki, Yargıtay eski bir kararında bu durumda meşru savunmanın varlığını kabul etmiştir:

“Nefsine karşı vukubulan silahla tecavüzü defetmek zarureti ile öldürülmesi kastedilen şahsa yapılan atışta, çıkan merminin başka bir kişiye isabetle öldürülmesinde, meşru müdafaa hali mevcuttur.”: Yargıtay 1. CD, 26.2.1958, E. 1958/567, K. 1958/505.

¹³¹⁴ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 25.2.2014 tarihli ve E. 2013/1-765, K. 2014/92 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Muhammet, 10.07.2010 tarihinde eve geldiğinde kızı Bahar'la tartışır ve ona vurmaya başlar. Bahar, babasıyla beraber oturduğu evin alt katında babaannesi Gülafer'in oturduğu eve kaçar. Muhammet, arkadan gelerek, babaannesinin evinde de Bahar'a vurmaya devam eder. Gülafer, oğlu Muhammet'i durdurmak için araya girer. Bahar bu sırada, babası Muhammet'ten korunabilmek için Gülafer'in arkasına saklanır. Muhammet'in savurduğu yumruk Bahar yerine Gülafer'in boyun bölgesine isabet eder. Hastaneye kaldırılan Gülafer, olaydan on üç gün sonra Hastanede ölür.

İlk Derece Mahkemesi, Muhammet hakkında **neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama** suçundan dolayı TCK, m. 86, f. 3; m. 87, f. 4 ... hükümleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılması yönünde mahkumiyet hükmü kurmuştur.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu mahkumiyet hükmünün onanmasına karar vermiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise, bu onama kararına aşağıdaki gerekçe ile itiraz etmiştir:

“Sanığın bir anlık öfke ile ve kendisini sinirlendiren kızı Bahar'ın üzerine doğru giderken, Bahar'ın arkasına sığınan veya araya girmek isteyen maktül anneye değil kızı Bahar'a doğru atılan sert bir tokadın kazara maktül anneye vurulması söz konusu olmadığından hareket iradi olmayıp, dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamaktır. İradi bir hareketle kızına attığı yumruk veya tokat, kızı Bahar'a değil de ölene değmiş ve öleni yaralanmıştır. Ancak gerçekleşen

Buna karşılık, A'nın silahından çıkan mermi çekirdeklerinden birinin duvara çarpıp sekmesi sonucunda C isabet alır ve C ölürse, A tarafından ikinci bir suçun işlendiğini kabul etmek gerekir. Bu durumda C'ye karşı işlenen suç, **taksirle ölüme sebebiyet verme suçu** olur ve **farklı neviden fikri içtima** (TCK, m. 44) hükümleri gereğince A hakkında daha ağır cezayı gerektiren suç olması itibarıyla sadece B'ye karşı **kasten öldürme suçundan** dolayı mahkumiyet hükmü kurmak gerekir.

Üçüncü ihtimal: A, otomobiliyle hareket halindeki B'yi öldürmek kastıyla silahıyla birkaç el ateş eder. A isabet almaz. Ancak, otomobilde bulunan C isabet alarak ölür. Yapılan atışlardan dolayı araçta hasar meydana gelir.

sonucu yani ölümü öngörememiştir. Diğer bir anlatımla, sanığın kastı, ölene yönelik kasten yaralamaya ilişkin olmayıp, meydana gelen ağır sonuç olan 'ölüme' yönelik değildir. Kızına sinirlenen şüpheli, kızının kafasına veya vücut bütünlüğüne atılan yumruğun mağduru yaralayacağı objektif olarak öngörülebilir bir sonuç olmasına karşın, araya giren annesine değen darbenin meydana getirdiği ölümü öngörememiştir. Failin maktûlü yaralama kastıyla hareket ettiğine dair hiçbir somut delil bulunmadığı gibi böyle bir iddiada bulmamaktadır. Sanığın olayda meydana gelen ağır netice olan ölümden taksirle sorumlu tutulması" gerekir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar vermiştir.

Hukuki değerlendirmemiz:

Karara konu teşkil eden olay bakımından sorunu iki yönden ele almak gerekir.

Birincisi, bananın kızına karşı işlediği kasten yaralama suçu tek bir suçtur. Her ne kadar bu yaralama suçunun icrası bağlamında birden fazla tokat ve yumruk söz konusu ise de, bunların hepsini hukuki anlamda **tek bir fiil** olarak kabul etmek gerekir. Çünkü bu hareketler, bir kasta dayalı olarak ve araya kast birliğini kaldırarak düzeyde bir fasıla girmeden gerçekleştirilmişlerdir. Bu itibarla, her ne kadar son yumruk Bahar'a değil de anne Gülafer'e isabet etmiş ise de, Muhammet tarafından kızı Bahar'a karşı **tamamlanmış kasten yaralama** suçu işlenmiştir.

Muhammet kızı Bahar'a vurmaya devam ederken, vurmasını engellemek için annesi araya girmiş ve Bahar da babasının darbelerinden korunmak için babaannesinin arkasına sığınmıştır. Ancak buna rağmen Muhammet saldırılarına devam etmiştir. Muhammet'in Bahar'a vurmak için savurduğu yumruklardan sonuncusu, Bahar'a değil, araya giren Gülafer'e isabet etmiştir. Gülafer de bu darbe sebebiyle bilahare ölmüştür.

Belirtmek gerekir ki, bu olayın kastı kaldıran veya kusurluluğu etkileyen hata halleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Muhammet, Bahar'a vurmak için savurduğu son yumruğun torununu korumak için araya giren Gülafer'e isabet edebileceğini öngörmüştür. Bu nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz gerekçesinde yapılan "öngörememiştir" şeklindeki değerlendirme doğru olmuştur.

Bu itibarla olayda, Muhammet tarafından annesi Gülafer'e karşı **neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten (olası kastla) yaralama** suçu işlenmiştir.

Bu durum karşısında Muhammet, hukuki anlamda tek bir fiil ile, kızı Bahar'a karşı tamamlanmış kasten yaralama suçunu ve ayrıca, annesi Gülafer'e karşı neticesi sebebiyle kasten (olası kastla) yaralama suçunu işlemiştir. Esasında **aynı neviden fikri içtima** hükümlerinin uygulanabileceği bir durum söz konusu olmakla birlikte; TCK, m. 43, f. 3'teki istisna hükmü gereğince Muhammet'in bu iki suçtan dolayı **gerçek içtima** hükümlerine göre cezalandırılması gerekirdi.

Bu ihtimalde, A tarafından işlenmiş üç ayrı suç söz konusudur. Birinci suç, A'nın B'ye karşı işlediği **teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürme suçu**dur. A'nın silahından çıkan mermi çekirdeklerinden birinin otomobilde bulunan C'ye isabeti sonucu C öldüğüne göre, ikinci suç, C'ye karşı **tamamlanmış kasten** (olası kastla) **öldürme suçu**dur. Üçüncü suç ise, B'ye karşı **mala zarar verme suçu**dur.

Aynı neviden fikri içtima hükümlerinin istisnalarından birini oluşturan bu durumda (TCK, m. 43, f. 2, 3), A hakkında **gerçek içtima** hükümlerine göre, hem B'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten (doğrudan kastla) öldürme suçundan, hem de C'ye karşı tamamlanmış kasten (olası kastla) öldürme suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekir. Ancak, **farklı neviden fikri içtima** hükümleri dikkate alınarak, A hakkında ayrıca mala zarar verme suçundan dolayı cezaya hükmedilmez¹³¹⁵.

Dördüncü ihtimal: A, B'yi öldürmek kastıyla silahıyla birkaç el ateş eder. Silahtan çıkan mermi çekirdeklerinden biri B'ye isabet eder ve B ölür. Mermi çekirdeklerinden diğeri ise hemen yanındaki C'ye isabet eder ve C yaralanır.

¹³¹⁵ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **16.9.2014** tarihli ve E. 2013/9-431, K. 2014/377 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; K, kendisine ait araçla yanında oğlu M olduğu halde şehir içinde seyrederken, aralarında daha önceden husumet bulunan S ile karşılaşır. K'nin aracını durdurarak S ile konuştuğu sırada S, yerden aldığı taş araca doğru atar. Taş, aracın arka camını kırarak içeri girer ve otomobilde oturan M'nin başına isabet eder; M yaralanır.

İlk Derece Mahkemesi bu olayda S hakkında mala zarar verme suçundan dolayı TCK, m. 151, f. 1; m. 52, f. 2 hükümlerine istinaden 2.400 TL ve ayrıca, kasten yaralama suçundan dolayı TCK, m. 86, f. 2; m. 52, f. 2 hükümlerine istinaden 2.400 TL adli para cezasına hükmetmiştir.

Söz konusu hükmü temyizden inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, söz konusu olayda, “*bir fiil ile kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının oluştuğu, sanığın hukuki durumunun TCK'nın 44. maddesi uyarınca farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği*” gerekçesiyle, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet hükmünü bozmuştur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki suçtan dolayı **gerçek içtima** hükümlerine göre cezalandırılması gerektiği yönündeki gerekçe ile Dairenin bu bozma kararına itiraz etmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, Daire bozma kararında olduğu gibi, söz konusu olayda **farklı neviden fikri içtima** hükümlerinin uygulanması gerektiği gerekçesiyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının reddine karar vermiştir.

Hukuki değerlendirmemiz: Bütün mercilerin kararlarında S'nin saldırısı K yönünden değerlendirme dışı bırakılmıştır. Oysa, husumet S ile K arasındadır. S, yerden aldığı taş otomobile doğru fırlatırken, kastı K'yi yaralamaktır. Ancak K yaralanmamıştır. Bu itibarla olayda S tarafından K'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten yaralama suçu işlenmiştir. Fırlatılan taş, otomobilde bulunan M'ye isabet etmiş ve M yaralanmıştır. Bu durumda mercilerin kabul ettiği gibi, olayda S tarafından M'ye karşı tamamlanmış kasten (olası kastla) yaralama suçu işlenmiştir. Keza, fırlatılan taş, otomobile hasar vermiş olmakla K'ye karşı ayrıca mala zarar verme suçu işlenmiştir. Bu durumda olayda S hakkında biri K'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten yaralama, diğeri M'ye karşı tamamlanmış kasten (olası kastla) yaralama suçlarından dolayı gerçek içtima hükümlerine göre cezaya hükmetmek ve fakat, ayrıca mala zarar verme suçundan dolayı ceza vermemek gerekir.

Bu durumda B'ye karşı işlenen suç, **kasten öldürme suçudur**. Keza aynı atışlardan çıkan mermi çekirdeklerinden diğeri B'nin hemen yanında bulunan C'ye isabet eder ve C yaralanır. Bu durumda C'ye karşı işlenen suç, **kasten (olası kastla) öldürme suçuna teşebbüs** olarak kabul etmek gerekir. **Aynı neviden fikri içtima** hükümlerinin istisnalarından birini oluşturan bu durumda (TCK, m. 43, f. 2, 3), A hakkında **gerçek içtima** hükümlerine göre hem B'ye karşı kasten (doğrudan kastla) öldürme suçundan, hem de C'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten (olası kastla) öldürme suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekir.

Buna karşılık, A'nın silahından çıkan mermi çekirdeklerinden birinin duvara çarpıp sekmesi sonucunda C isabet alır ve yaralanır ise, bu durumda ikinci bir suç olarak, C'ye karşı **taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçunun** oluştuğunu kabul etmek ve **farklı neviden fikri içtima** (TCK, m. 44) hükümleri gereğince daha ağır cezayı gerektiren suç olması itibarıyla A hakkında sadece B'ye karşı **kasten öldürme suçundan** dolayı mahkumiyet hükmü kurmak gerekir.

Beşinci ihtimal: A, B'yi öldürmek kastıyla silahıyla birkaç el ateş eder. Silah-tan çıkan mermi çekirdeklerinden biri B'ye isabet eder ve B yaralanır. Mermi çekirdeklerinden diğeri ise hemen yanındaki C'ye isabet eder ve C ölür.

Bu durumda B'ye karşı işlenen suç, **teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürme suçudur**. Keza aynı atışlardan çıkan mermi çekirdeklerinden diğeri B'nin hemen yanında bulunan C'ye isabet eder ve C ölür. Bu durumda ikinci suç olarak A'nın C'ye karşı işlediği suç, **kasten (olası kastla) öldürme suçudur**. **Aynı neviden fikri içtima** hükümlerinin istisnalarından birini oluşturan bu durumda (TCK, m. 43, f. 2, 3), A hakkında **gerçek içtima** hükümlerine göre hem B'ye karşı teşebbüs aşamasında kalmış kasten (doğrudan kastla) öldürme suçundan, hem de C'ye karşı tamamlanmış kasten (olası kastla) öldürme suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekir.

Buna karşılık, A'nın silahından çıkan mermi çekirdeklerinden birinin duvara çarpıp sekmesi sonucunda C isabet alır ve yaralanır ise, bu durumda ikinci bir suç olarak, C'ye karşı **taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçunun** oluştuğunu kabul etmek ve **farklı neviden fikri içtima** (TCK, m. 44) hükümleri gereğince daha ağır cezayı gerektiren suç olması itibarıyla A hakkında sadece B'ye karşı **teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürme suçundan** dolayı mahkumiyet hükmü kurmak gerekir.

Altıncı ihtimal: A, B'yi öldürmek kastıyla av tüfeğiyle bir el ateş eder. Silah-tan çıkan saçmalardan bir kısmı B'ye isabet eder ve B ölür. Saçmalardan bir kısmı ise, hemen yanındaki C'ye isabet eder ve C de ölür.

Bu durumda B'ye karşı işlenen suç, **kasten öldürme suçudur**. Keza saçmalardan bir kısmı B'nin hemen yanında bulunan C'ye isabet eder ve C ölür. Bu du-

rumda ikinci suç olarak A'nın C'ye karşı işlediği suç, **kasten (olası kastla) öldürme suçudur. Aynı neviden fikri içtima** hükümlerinin istisnalarından birini oluşturan bu durumda (TCK, m. 43, f. 2, 3), A hakkında **gerçek içtima** hükümlerine göre hem B'ye karşı kasten (doğrudan kastla) öldürme suçundan, hem de C'ye karşı kasten (olası kastla) öldürme suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmetmek gerekir^{1316, 1317}.

¹³¹⁶ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **25.2.2014** tarihli ve E. 2013/1-765, K. 2014/92 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; Muhammet, 10.07.2010 tarihinde eve geldiğinde kızı Bahar'la tartışır ve ona vurmaya başlar. Bahar, babasıyla beraber oturduğu evin alt katında babaannesi Gülafer'in oturduğu eve kaçar. Muhammet, arkadan gelerek, babaannesinin evinde de Bahar'a vurmaya devam eder. Gülafer, oğlu Muhammet'i durdurmak için araya girer. Bahar bu sırada, babası Muhammet'ten korunabilmek için Gülafer'in arkasına saklanır. Muhammet'in savurduğu yumruk Bahar yerine Gülafer'in boyun bölgesine isabet eder. Hastaneye kaldırılan Gülafer, olaydan on üç gün sonra Hastanede ölür.

İlk Derece Mahkemesi, Muhammet hakkında **neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama** suçundan dolayı TCK, m. 86, f. 3; m. 87, f. 4 ... hükümleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılması yönünde mahkumiyet hükmü kurmuştur.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu mahkumiyet hükmünün onanmasına karar vermiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise, bu onama kararına aşağıdaki gerekçe ile itiraz etmiştir:

*“Sanığın bir anlık öfke ile ve kendisini sinirlendiren kızı Bahar'ın üzerine doğru giderken, Bahar'ın arkasına sığınan veya araya girmek isteyen maktül anneye değil kızı Bahar'a doğru atılan sert bir tokadın kazara maktül anneye vurulması söz konusu olmadığından hareket iradi olmayıp, dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamaktır. İradi bir hareketle kızına attığı yumruk veya tokat, kızı Bahar'a değil de ölene değmiş ve öleni yaralanmıştır. Ancak gerçekleşen sonucu yani ölümü **öngörememiştir**. Diğer bir anlatımla, sanığın kastı, ölene yönelik kasten yaralamaya ilişkin olmayıp, meydana gelen ağır sonuç olan 'ölüm' yönelik değildir. Kızına sinirlenen şüpheli, kızının kafasına veya vücut bütünlüğüne atılan yumruğun mağduru yaralayacağı objektif olarak öngörülebilir bir sonuç olmasına karşın, araya giren annesine değen darbenin meydana getirdiği ölümü **öngörememiştir**. Failin maktülü yaralama kastıyla hareket ettiğine dair hiçbir somut delil bulunmadığı gibi böyle bir iddiada bulunmamaktadır. Sanığın olayda meydana gelen ağır netice olan ölümden taksirle sorumlu tutulması”* gerekir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar vermiştir.

Hukuki değerlendirmemiz:

Karara konu teşkil eden olay bakımından sorunu iki yönden ele almak gerekir.

Birincisi, bananın kızına karşı işlediği kasten yaralama suçu tek bir suçtur. Her ne kadar bu yaralama suçunun icrası bağlamında birden fazla tokat ve yumruk söz konusu ise de, bunların hepsini hukuki anlamda **tek bir fiil** olarak kabul etmek gerekir. Çünkü bu hareketler, bir kasta dayalı olarak ve araya kast birliğini kaldıracak düzeyde bir fasıla girmeden gerçekleştirilmişlerdir. Bu itibarla, her ne kadar son yumruk Bahar'a değil de anne Gülafer'e isabet etmiş ise de, Muhammet tarafından kızı Bahar'a karşı **tamamlanmış kasten yaralama** suçu işlenmiştir.

Muhammet kızı Bahar'a vurmaya devam ederken, vurmasını engellemek için annesi araya girmiş ve Bahar da babasının darbelerinden korunmak için babaannesinin arkasına sığınmıştır. Ancak buna rağmen Muhammet saldırılarına devam etmiştir. Muhammet'in Bahar'a vurmak için savurduğu yumruklardan sonuncusu, Bahar'a değil, araya giren Gülafer'e isabet etmiştir. Gülafer de bu darbe sebebiyle bilahare ölmüştür.

Belirtmek gerekir ki, bu olayın kastı kaldıran veya kusurluluğu etkileyen hata halleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yedinci ihtimal: A, B'ye zarar vermek kastıyla evinin camına doğru taş fırlatır. Camı kıran taş, mutfakta bulunan C'ye isabet eder ve C yaralanır.

Bu ihtimalde, A'nın B'ye karşı işlediği **mala zarar verme suçu** tamamlanmıştır. Keza, bu fiil ile A, mutfakta bulunan C'ye karşı **bilinçli taksirle yaralama-**

Muhammet, Bahar'a vurmak için savurduğu son yumruğun torununu korumak için araya giren Gülafer'e isabet edebileceğini öngörmüştür. Bu nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz gerekçesinde yapılan "öngörememiştir" şeklindeki değerlendirme doğru olmamıştır.

Bu itibarla olayda, Muhammet tarafından annesi Gülafer'e karşı **neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten (olası kastla) yaralama** suçu işlenmiştir.

Bu durum karşısında Muhammet, hukuki anlamda tek bir fiil ile, kızı Bahar'a karşı tamamlanmış kasten yaralama suçunu ve ayrıca, annesi Gülafer'e karşı neticesi sebebiyle kasten (olası kastla) yaralama suçunu işlemiştir. Esasında **aynı neviden fikri içtima** hükümlerinin uygulanabileceği bir durum söz konusu olmakla birlikte; TCK, m. 43, f. 3'teki istisna hükmü gereğince Muhammet'in bu iki suçtan dolayı **gerçek içtima** hükümlerine göre cezalandırılması gerekirdi.

¹³¹⁷ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **5.2.2019** tarihli ve E. 2018/310, K. 2019/62 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; S, av tüfeğiyle R'yi hedef alarak ve öldürme kastıyla bir el ateş eder. Ancak, R'nin kendini hemen yana atması sebebiyle, yaralanmaktan kurtulur. Tüfek namlusundan çıkan çok sayıda saçma tanesi R'nin hemen arkasında bulunan kızı P'ye isabet eder ve P yaralanır.

Bu olayda R'ye karşı işlenen **kasten öldürme suçunun teşebbüs** aşamasında kaldığı kabul edilmekle birlikte, çözümlenmesi gereken hukuki sorunlar sırasıyla şunlardır:

- 1) P'nin yaralanması bakımından S'nin işlediği suç olası kastla yaralama suçu mudur, yoksa teşebbüs aşamasında kalmış olası kastla öldürme suçu mudur?
- 2) Birinci soruya verilecek olan cevaba göre, S hangi suçtan veya suçlardan dolayı ceza hukuku bakımından sorumlu tutulmalıdır? Başka bir ifadeyle, işlendiği kabul edilen suçlar bakımından içtima kuralı uygulanacaktır?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu olayda, S'nin P'ye karşı işlediği suçun **olası kastla yaralama** suçu (TCK, m. 86, f. 1, f. 3, bent a; m. 21, f. 2) olduğunu kabul etmiştir.

Yine Ceza Genel Kurulu, bu olayda, neticeyi değil, **fiili** esas alarak, bir fiil ile iki ayrı suçun işlendiğini kabul etmiş ve farklı neviden fikri içtima hükümlerine istinaden, **S'nin sadece teşebbüs aşamasında kalmış olan kasten öldürme suçundan dolayı cezalandırılması, ayrıca olası kastla yaralama suçundan dolayı cezalandırılması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur**. Ceza Genel Kurulu Kararını içtima ile ilgili kısmı oy çokluğu ile almıştır.

Üyelerden bir kısmı ise, klasik suç teorisinin etkisindeki yazarların görüşlerine ve yine Yargıtay Ceza Genel Kurulunun geçmişteki farklı içtihatlarına atıfta bulunarak, bu durumda neticeden hareketle, iki ayrı suçun oluştuğu ve bu suçlardan dolayı gerçek içtima hükümlerine istinaden cezaya hükmetmek gerektiği gerekçesiyle karşı oy kullanmışlardır.

Keza, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **18.10.2018** tarihli ve E. 2015/158, K. 2018/444 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; T, av tüfeğini üç dört metre mesafede bulunan K'ye doğrultarak bir el ateş eder. Tüfek namlusundan çıkan çok sayıda saçma tanesi K'ye isabet eder ve K, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanır. Ancak bu saçma tanelerinden bir kısmı K'nin hemen yanında bulunan O'nun bacağına isabet eder ve O, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanır.

Ceza Genel Kurulu, bu olayda da **bir fiilin** işlendiğini ve bu fiil ile iki ayrı suçun işlendiğini kabul ederek, farklı neviden fikri içtima hükümlerine göre sadece teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürme suçundan dolayı cezaya hükmedilmesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur.

ya sebebiyet verme veya olası kastla yaralama suçunu işlemiş olur. **Farklı neviden fikri içtima** (TCK, m. 44) hükümlerine göre, somut olayda A hakkında bu suçlardan hangisi daha ağır cezayı gerektirirse, bu suçtan dolayı cezaya hükmetmek gerekir.

Sekizinci ihtimal: Meşru savunma halinde olan A, saldırısını etkisiz kılmak amacıyla B'ye silahla birkaç el ateş eder. İsabet alan B ölür veya yaralanır. Ancak, silahtan çıkan mermi çekirdeklerinden biri, C'ye isabet eder. C de ölür veya yaralanır.

Yukarıda tek neticeli hedefte sapma ile ilgili “yedinci ihtimal” çerçevesinde yapılan açıklamalar, bu ihtimal için de geçerlidir.

Bütün bu ihtimallerde sorun, yukarıda olası kastla işlenen suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanabilirliği ile bağlantılı olarak yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi, yaralama neticeleri bakımından **olası kastla yaralama suçunun** mu yoksa **olası kastla öldürme suçuna teşebbüsün** mü oluştuğu hususunda temerküz etmektedir. Klasik anlayışta, bu ihtimallerde yaralama neticeleri bakımından olası kastla yaralama suçu oluştuğu kabul edildiği için, farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır¹³¹⁸. Oysa bu gibi hallerde, yaralama neticeleri bakımından olası kastla yaralama suçunun değil, **olası kastla öldürme suçuna teşebbüsün** oluştuğu kabul edildiği takdirde, sorun kolaylıkla çözümlenebilmektedir.

IV. Doktrinde, farklı neviden fikri içtimadan farklı olarak “görünüşte içtima”ın da varlığı kabul edilmektedir. Bu ayırıma göre, “görünüşte içtima” halinde, “doğrudan doğruya normlar arasındaki ilişkiden, bu normlardan sadece birinin uygulanabileceği sonucuna varılmaktadır¹³¹⁹. “Görünüşte içtima” halinde ceza normlarının ve suçların çokluğunun tamamen görünüşte olduğu, aslında fail tarafından gerçekleştirilen fiile uygulanacak bir tek ceza normunun bulunduğu açıktır¹³²⁰. Aslında “görünüşte içtima”a örnek olarak gösterilen hallerde bir yorum sorunu bulunmaktadır. Örneğin, “özel - genel norm ilişkisi”nin bulunduğu hallerde, yorum metotlarına başvurarak fiile uygulanacak normun, özel norm olduğunda kuşku yoktur.

Bir fiile ilgili olarak görünüşte uygulanabilir durumda bulunan çeşitli suç tanımlarından birisi diğer bir tanımda yer alan unsurların yanı sıra bazı ilave un-

¹³¹⁸ Bu çözüm biçimi bakımından Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **5.2.2019** tarihli ve E. 2018/310, K. 2019/62 sayılı; **16.9.2014** tarihli ve E. 2013/9-431, K. 2014/377 sayılı; **3.12.2013** tarihli ve E. 2012/1-1569, K. 2013/575 sayılı kararlarında gerekçe olarak yer verilen açıklamalar ve varılan sonuçlar önemlidir.

¹³¹⁹ ÖNDER, C. II-III, sh.480; SCHÖNKE/SCHRÖDER, § 52Rdn., Vorbemerkungen 102.

¹³²⁰ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 414 vd.

surları ihtiva edebilir. Bu gibi durumlarda “*genel norm – özel norm ilişkisi*” söz konusu olup; olaya “genel norm”un uygulanmasını engelleyen “özel norm” uygulanır¹³²¹. Örneğin, *güveni kötüye kullanma* suçu (m. 155) karşısında, *zimmet* suçu (m. 247; 5411 s. Bankacılık Kanunu, m. 160); *görevi kötüye kullanma* suçu (m. 257, f. 1, 3) karşısında, *zimmet* (m. 247), *irtikâp* (m. 250) veya *rüşvet* (m. 252) suçları; *görevi kötüye kullanma* suçu (m. 257, f. 2) karşısında, *kamu görevlisinin suçu bildirmemesi* suçu (m. 279) özel norm niteliği taşımaktadır¹³²².

¹³²¹ “Lex specialis derogat legi generalis” (Özel norm, genel normun uygulanmasını engeller) kuralı. Ayrıntılı bilgi için bkz. İÇEL, Suçların İçtimai, sh: 173.

¹³²² **Genel norm - özel norm** uygulaması bakımından aşağıdaki karar önem taşımaktadır:

I. Marmaris 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 27.2.2008 tarihli ve E.2006/441, K. 2008/62 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, S, izin ve ruhsat almadan bir yapı inşa eder. Yapının üzerinde inşa edildiği yer, belediye sınırları dışında, 3. derece doğal sit sınırları ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzenleme planı içinde kalır.

Bu olayda Mahkeme aşağıdaki gerekçeyle mahkûmiyet hükmü kurar:

“TCK nun 184/1. maddesinde; yapı ruhsatıyesı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişinin bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüş, aynı maddenin 4. fıkrasında da, bu hükmün ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Kanunlarda ve TCK nun 184. maddesinin gerekçesinde, “özel imar rejimine tabi yer” kavramının açık tanımı yapılmamış ise de, İmar Kanunu ve diğer kanunlarda (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Boğaziçi Kanunu vb) yapılan imar ile ilgili düzenlemeler dikkate alındığında, özel imar rejimine tabi yer kavramı ile; ekonomik, kültürel, doğal ya da başka nedenler gözetilerek, yapılaşmalar bakımından bazı özel usul ve esasların getirildiği, yapılaşmaların ilgili Kurumlarca verilecek izin ya da ruhsat koşuluna bağlı tutulabildiği yerlerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Özel çevre koruma bölgesi ilan edilen yerlerde yapılacak yapılaşmalar bakımından bazı sınırlamalar ve ruhsat koşulu getirilmiş olması nedeniyle, Mahkememizce, bu bölgelerin de özel imar rejimine tabi yerlerden sayılması gerektiği düşünülmüştür.

Diğer taraftan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65/b. maddesinde; “Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına, koruma amaçlı imar planlarına ve koruma bölge kurullarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanun’un 9. maddesinde de; esaslı onarım, inşaat, tesisat sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı ve benzeri işlerin inşai ve fiziki müdahale sayılacağı hükme bağlanmıştır.

TCK nun 44. maddesinde de fikri içtima düzenlenmiş olup, işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişinin, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılacağı öngörülmüştür. Madde gerekçesinde de, kişinin işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşumuna neden olabileceği, bu durumda, failin bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren suç nedeniyle cezalandırılması yoluna gidilmesinin gerektiği belirtilmiştir. Fikri içtima halinde tek fiil olup, bu fiil ile Kanunun değişik hükümleri ihlal edilmektedir. İhlal edilen değişik hükümler, bir başka deyişle farklı suçlar aynı Kanunda olabileceği gibi, değişik Kanunlarda da olabilir.

...S’nin fiili tek olup, söz konusu fiil ile, TCK’nın 184/1. maddesinde ve 2863 sayılı Kanun’un 65/b. maddesinde düzenlenmiş olan birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Ceza Kanunu genel bir kanun olup, 2863 sayılı Kanun’un 65/b. maddesinde yapılan düzenleme, Ceza Kanununa göre özel bir düzenlemedir. Ayrıca, TCK’nın 44. maddesi uyarınca, işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişinin,

bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması gerekmektedir. Maddelerde öngörülen cezalar karşılaştırıldığında, hapis cezalarının üst sınırları eşit olmakla birlikte, alt sınırın iki yıldan başlaması ve hapis cezasının yanında adli para cezası öngörülmüş olması nedeniyle, 2863 sayılı Kanun'un 65/b. maddesinde düzenlenen suçun, TCK'nun 184/1. maddesinde düzenlenen suçta göre daha ağır cezayı gerektiren suç olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

S'nin fiilinin, 2863 sayılı Kanun'un 65/b. maddesinde yazılı suç ile TCK'nun 184/1. maddesinde yazılı suçu oluşturduğu, özel hüküm olması ve/veya ağır cezayı gerektirmesi nedeniyle sanığın 2863 sayılı Kanun'un 65/b. maddesi uyarınca cezalandırılmasının gerektiği kanaatine varılmış ve bu nedenle sanığın cezalandırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Bir an için S hakkında düzenlenen iddianamede, 2863 sayılı Kanun'un 65/b. maddesi uyarınca cezalandırılması yolunda talep ve bu konuda açılmış bir dava olmadığı ileri sürülebilir ise de, CMK'nun 225/1. maddesi uyarınca, iddianamede unsurları gösterilen suçla ilişkin fiil ve fail hakkında hüküm verilebileceği ve mahkemenin fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı olmayacağı açıktır. İddianamede sanığın "... yetkili birimden izin ve yapı ruhsatıyes i almaksızın imar mevzuatına aykırı olarak tek katlı betonarme bina yaptığının..." belirtilmiş olması nedeniyle, Mahkememizce, 2863 sayılı Kanun'un 65/b maddesinde düzenlenen suçu oluşturan fiil bakımından da kamu davasının açılmış olduğu kabul edilmiştir."

Açıklanan nedenlerle, Mahkeme,

- 1- S hakkında, 2863 sayılı Kanun'un 65/b. maddesi uyarınca takdiren 2 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA,
- 2-Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak, TCK'nun 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, 1 yıl 8 ay hapis ve 25 gün adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA,
- 3- TCK'nın 52/2. maddesi uyarınca, sanığın ekonomik durumu ve şahsi hallerine göre, 25 gün adli para cezasının günlüğü takdiren 20,00 TL'den hesaplanarak, sanığın 500,00 TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA,
- 4- S'nin kişisel ve ekonomik durumu nedeniyle, TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca, verilen para cezasının birer ay aralıklarla 5 eşit taksitte ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edilmesine, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine,
- 5- S'nin sabıkasız oluşu ve yargılama sürecinde gösterdiği davranışları nedeniyle tekrar suç işlemeyeceğine dair Mahkememize yeterli kanaat geldiğinden, verilen hapis cezasının TCK'nın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESİNE,
- 6- S'nin, TCK'nun 51/3. maddesi uyarınca, takdiren 2 yıl süre ile denetim altında bulundurulmasına, kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak, TCK'nun 51/6. maddesi uyarınca denetim süresinin yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlendiği takdirde, ertelenen cezanın tamamen veya kısmen çektirilmesine karar verileceğinin ihtarına,

hükmeder.

II. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, aşağıdaki gerekçeyle söz konusu mahkumiyet hükmünü bozar:

"Dairemiz kararlarında "özel imar rejimine tabi yerler"; 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gibi özel imar düzenlemeleri ve kısıtlamaları getiren yerler şeklinde anlaşılmaktadır. Nitekim 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 4. maddesinde, belirtilen nitelikteki özel kanun hükümlerinin geçerliliği kabul edilmiştir.

Belirtilen kanuni düzenlemeler karşısında, TCK'nın 184/1. maddesinde ruhsatsız veya ruhsata aykırı "bina yapılması" bağlamında özel kanunlardaki hükümlere göre daha özel nitelikli bir norm olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda özel hüküm-genel hüküm çatışmasında "özel normun önceliği ilkesi" gereği yalnızca TCK'nın 184/1. maddesi uygulanmalıdır.

Bir suç tanımının, daha ağır cezayı gerektiren başka bir suçtan dolayı cezaya hükmolunmadığı takdirde uygulanabilirliğinin kabulü halinde, **tali ve tamamlayıcı suç** söz konusudur. “Yardımcı norm”lar olarak da ifade edilen¹³²³ tali ve tamamlayıcı suçlar, kanunda bulunması olası boşluk ve eksiklikleri tamamlama fonksiyonu görürler ve aynı fiille ilgili olarak daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç tanımına göre cezaya hükmolunmaması halinde uygulanabilirler. Tali ve tamamlayıcı suç tanımları, farklı nitelikte fikri içtima halinin bir örneğini oluşturmaktadır. Uygulamada, tali ve tamamlayıcı suçu oluşturan fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturup oluşturmadığı, hakim tarafından özellikle araştırılacaktır.

Örneğin, “*sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, **fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.***” (m. 245, f. 3; ayrıca bkz. m. 261, f. 1).

Keza, 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre, örneğin mahkeme salonlarına, eğitim kurumlarına silah sokan “*kişiler, **fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde,***” bu Kanunun Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı cezalandırılır. Bu suçtan dolayı kişinin cezalandırılabilmesi için, suçun konusunu oluşturan silahın ruhsatsız olması şart değildir. Ruhsatlı silahın söz konusu yerlere sokulması halinde dahi, Ek 1. maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan suç oluşur. Silahın ruhsatsız olması halinde ise, fiil aynı Kanunun 13. veya 15. maddelerinde tanımlanan ruhsatsız silah bulundurmak veya taşımak suçunu oluşturduğu için, daha ağır cezayı gerektirecektir ve bu

Bu açıklamalar doğrultusunda sanığın, Bakanlar Kurulunun 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı kararı ile ilan edilen Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 14.02.1996 gün ve 5576 sayılı kararı ile tescil edilen III. Derece Sit alanında yetkili kurumlardan izin ve yapı ruhsatı alınmadan tek katlı betonarme bina inşa etmek biçiminde gerçekleşen eyleminin, 5237 sayılı TCK'nın 184/1. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden eylemin aynı zamanda 2863 sayılı kanunun 65/b maddisini de ihlal ettiğinden söz edilerek 5237 sayılı TCK'nın 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren 2863 sayılı kanun uyarınca hüküm kurulması,

Yasaya aykırı"dır (27.03.2012, E. 2010/15293, K. 2012/7059).

III. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer gerekçelerin yanı sıra, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun, Türk Ceza Kanununa nazaran “özel kanun” niteliğinde olduğu mülahazasıyla bu karara itiraz eder (25.6.2012, 2008/184144).

Bu itiraz üzerine Daire, söz konusu bozma kararının kaldırılmasına karar verir.

Ancak Daire, söz konusu suçun 26.4.2005 tarihinde işlenmiş olması karşısında, “sanık yararına olan 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık olağanüstü dava zamanaşımının gerçekleştiği” gerekçesiyle, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca **KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE** karar verir. (9.5.2013, E. 2012/28180, K. 2013/14227).

¹³²³ İÇEL, Suçların İçtimalı, sh: 175.

nedenle, artık Ek 1. maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı faile ceza verilmeyecektir.¹³²⁴

Bu bağlamda ayrıca, *aslî norm – talî norm ilişkisi* üzerinde durmak gerekir. Kişinin işlemiş bulunduğu fiil, bir suçtan dolayı *fail* olarak, diğer bir suçun işlenişine iştirakten dolayı *yardım eden* (şerik) olarak sorumluluğu gerektirebilir. Örneğin resmi belgede sahtecilik suçunun göreviyle bağlantılı olarak kamu görevlisi tarafından işlenmesi, bu suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurunu oluşturmaktadır (m. 204, f. 2). Resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturan icra hareketlerinin kamu görevlisi olan ve olmayan iki kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, kamu görevlisi olmayan kişi, kamu görevlisinin işlemiş bulunduğu resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı ancak yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulabilir. Çünkü, kamu görevlisi olmayan kişi her ne kadar bu suçun icra hareketlerini kamu görevlisiyle birlikte gerçekleştirmiş ise de, kamu görevlisi sıfatını taşımadığı için, resmi belgede sahtecilik suçunun bu nitelikli şeklinin faili olamaz. Diğer suç ortağının kamu görevlisi olduğunu bilse bile, kamu görevlisi olmayan kişi, kamu görevlisinin işlemekte olduğu resmi belgede sahtecilik suçuna (m. 204, f. 2) ancak yardım eden olarak iştirakten dolayı sorumlu tutulabilir. Fakat, kamu görevlisi olmayan kişinin bu davranışı, aynı zamanda, resmi belgede sahtecilik suçunun temel şekli (m. 204, f. 1) açısından fail olarak sorumlu tutulmasını gerektirmektedir.

Böylece, kamu görevlisi olmayan kişinin gerçekleştirdiği davranış, hem kamu görevlisi sıfatını taşıyan bir başkasının işlemekte olduğu resmi belgede sahtecilik suçuna yardım eden sıfatıyla *şerik* olarak sorumluluğunu, hem de ilgili suçun temel şekli bakımından *fail* olarak sorumluluğunu gerekli kılmaktadır. **Failliğin şerikliğe nazaran asliliği kuralı** gereğince, bu durumda, kamu görevlisi sıfatını taşımayan kişiyi sadece fail olarak sorumlu tutulmasını gerektiren resmi belgede sahtecilik suçunun temel şeklinden dolayı cezalandırmak mümkün olacaktır.

¹³²⁴ Aynı yönde başka düzenlemeler için bkz. 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, m. 171; 28.4.2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, m. 18, f. 1.

Başka kanunlarda da tali ve tamamlayıcı suç tanımlarına yer verilmiştir. Şu örnekler, bu bağlamda ayrıca zikredilebilir:

1) 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, ihtiyati tedbir kararının gereklerine aykırı hareket eden kişi, “*fiili daha ağır cezayı gerektiren (başka) bir suç oluşturmadığı takdirde,*” bu Kanunun 113/A maddesinde tanımlanan suçtan dolayı cezalandırılacaktır.

2) 5.5.1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 76. maddesine göre, “*Bir grev oylamasının sonucuna tesir etmek maksadıyla hile veya tehdit veya cebir kullananlar, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren (başka bir) suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.*”

3) 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47. maddesine göre; *bu maddenin A, B veya C bentlerinde sayılan fiilleri işleyen kişiler, fiilleri “diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren (başka) bir suç oluşturmadığı takdirde;*” bu madde hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

VI. Suç ve Kabahatin İçtimaı

5326 s. Kabahatler Kanununun “İçtima” başlıklı 15. maddesine göre;

“(1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idari para cezasından başka idari yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.”

Bu maddenin **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Maddenin birinci fıkrasında, Türk Ceza Kanununun farklı neviden fıkri içtima ilişkili hükmüne paralel bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, bu hüküm, sadece idari para cezaları açısından uygulanabilir. Bu itibarla, bir fiille gerçekleştirilen birden fazla kabahatten her biri açısından idari para cezası dışında başka idari yaptırımlar öngörülmüş ise, bu yaptırımların hepsine birden karar verilir.

Maddenin ikinci fıkrasında, Türk Ceza Kanununun zincirleme suç ilişkili hükümlerinin kabahatler açısından uygulanamayacağı vurgulanmıştır. Bir kabahatin birden fazla işlenmesi durumunda gerçek içtima hükümlerine göre, her bir fiille ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezasına karar verilecektir.

Bir fiil, bazı durumlarda hem suç hem de kabahat oluşturabilir. Maddenin üçüncü fıkrası, bu hallere özgü ve fakat sadece içtima ile ilgili bir hüküm içermektedir. Bu gibi durumlarda kişi hakkında sadece suçtan dolayı ceza veya güvenlik tedbirine hükmedilebilecektir; fiilin kabahat oluşturması dolayısıyla ayrıca idari yaptırım uygulanamayacaktır. Böylece, “non bis in idem” kuralına suçlarla kabahatler arasında da geçerlilik tanınmıştır. Ancak, suçtan dolayı ceza veya güvenlik tedbirine hükmedilemeyen hallerde, kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanabilecektir.”

TBMM Adalet Komisyonunda Tasarı üzerinde yapılan çalışmalar sırasında, “‘İçtima’ başlıklı 15’inci maddenin ikinci fıkrasına, kesintisiz (mütemadi) kabahatler dolayısıyla idari yaptırım uygulanmasında esas alınacak fiil sayısını belirlemeye yönelik bir cümle eklenmiştir.”¹³²⁵

¹³²⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840, sh. 12.

Görüldüğü üzere, Türk Ceza Kanunu gibi Kabahatler Kanunu da , içtima bakımından **gerçek içtima** kuralını benimsemiştir:

“Kaç fiil varsa o kadar (kabahat), kaç (kabahat) varsa o kadar ceza vardır.”¹³²⁶

Başka bir ifadeyle, Kabahatler Kanunu, “**fiil sayısınca kabahat vardır ve kabahat sayısınca da idari para cezası uygulanır**” prensibini benimsemiştir.

Bu kuralın bir **istisnasına**, söz konusu Kanunun 15. maddesinin birinci fıkrasında yer verilmiştir. Madde gerekçesinde de vurgulandığı üzere, birinci fıkranın birinci cümlesinde, Türk Ceza Kanununun 44. maddesi hükmüne paralel olarak kabahatler bakımından **farklı neviden fikri içtima** düzenlenmiştir.

Farklı neviden fikrî içtima halinde, **bir fiil** ile kanunda tanımlanan **birden fazla farklı kabahat** işlenmektedir. Bu kabahatlerin her birinden dolayı ayrı ayrı idari para cezası verme imkânı varken; Kanun koyucu **bu kabahatlerden en ağırından dolayı idari para cezası** verilmesi ilkesini benimsemiştir.

Buna göre; farklı nev’iden fikrî içtimadan söz edebilmek için, a) fiilin tek olması, b) bu fiil ile kanunda tanımlanan birden fazla kabahatin işlenmesi gerekir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, farklı neviden fikrî içtima halinde, **bir fiil** ile kanunda tanımlanan **birden fazla farklı kabahat** işlenmektedir.

Buna karşılık, maddenin ikinci fıkrasında, Türk Ceza Kanununun 43. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen zincirleme suçla ilişkin hükmün tersi bir düzenlemeye yer verilmiştir:

“Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir.”

Buna göre, bir kabahatin birden fazla işlenmesi durumunda **gerçek içtima** hükümlerine göre, her bir fiille ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezasına karar verilecektir.

Kabahatler Kanununun 15. maddesinin ikinci fıkrasında, Türk Ceza Kanununun 43. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen zincirleme suçla ilişkin hükmün kabahatler bakımından uygulanamayacağı açıkça hüküm altına alındığı halde; 43. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen aynı neviden fikri içtimaa ilişkin olarak düzenlemeye yer verilmemiştir. Bunun dayandığı temel düşünce şudur: Bir fiilin kabahat olarak yaptırım altına alınması için bu fiil nedeniyle belirli bir kişinin mağdur edilmiş olup olmaması göz önünde bulundurulmamaktadır. Kabahatlere ilişkin düzenlemeler, belirli bir kişinin mağduriyetini önlemekten ziyade, toplu-

¹³²⁶ TBMM Adalet Komisyonu’nun Türk Ceza Kanunu Tasarısına ilişkin 3.8.2004 tarih ve Esas: 1/593, Karar: 60 sayılı Raporu, TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 229. İçtima konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 3. bası, Ankara 2008, sh. 527 vd.

mun belirli bir alanındaki veya belirli bir kurumun işleyişine ilişkin düzeni korumayı amaçlayan ve bu düzeni bozucu nitelik taşıyan fiillerin bu kapsamda yaptırım altına alınmasını sağlayan düzenlemelerdir. Bu nedenledir ki, Kabahatler Kanununun karşılığını oluşturan Almanya mevzuatındaki kanunun adı, “**Düzene Aykırılıklar Kanunu**”dur (“Gesetz über Ordnungswidrigkeiten”).

Kabahatler Kanununa ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında, maddenin ikinci fıkrasına kesintisiz fiille işlenen kabahatler bakımından bir hüküm eklenmiştir:

“Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.”

Bu düzenleme özellikle **ihmali davranışla işlenen kabahatler** bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Mevzuatta kişi veya kurumlara yüklenen belirli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin ihmal edilmesi dolayısıyla idari para cezası verilmesi gereken hallerde, mevzuatla yüklenen belirli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesini ihmal edildiği süre zarfında bu kabahat işlenmeye devam ediliyor demektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi dolayısıyla idari para cezası verildikten sonra, buna rağmen söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesinin ihmal edilmesi halinde, **idari yaptırım kararı verildikten sonraki ihmali davranış ayrı bir kabahat olarak değerlendirilecektir.**

İşaret etmek gerekir ki, **salt bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi dolayısıyla idari para cezası verilmesi ile bir yükümlülük yerine getirilmeden işlem yapılması dolayısıyla idari para cezası verilmesini birbirinden ayırmak gerekir.**

Örneğin 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, tüketicinin satıcı ile arasındaki abonelik sözleşmesinin iptalini talep etmesi halinde satıcının bu sözleşmeyi belirli bir süre zarfında feshetmesi gerekir (m. 11/A, f. 2). Bu sözleşmenin kanunda öngörülen süre zarfında feshedilmemesi halinde, salt bir yükümlülük yerine getirilmemiş olmaktadır ve bu nedenle satıcıya idari para cezası verilmektedir (4077 s. Kanun, m. 25, f. 2).

Keza, hesap sahibi tarafından talep edilmesine rağmen, banka tarafından kredi kartının iptal edilmemesi halinde, idari yaptırım uygulanması gereken fiil sayısını belirlerken, iptali talep edilen kredi kartlarının sahibi olan müşterilerin sayısı göz önünde bulundurulamaz. Bu durumda **ihmali davranışla işlenmiş tek bir fiilden** söz edilebilir.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmeliğin 18’inci maddesinin (2) numaralı fıkrası,

“Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin fes-

hine ilişkin kart hamiline yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur."

hükümünü taşımaktadır. Bu hükme göre, hesap sahibinin talebi üzerine banka tarafından kredi kartının talep tarihinden itibaren yedi gün içinde iptal edilmesi gerekmektedir. Yedi günlük sürenin geçmesine rağmen söz konusu yükümlülüğün banka tarafından yerine getirilmemesi halinde, idari para cezasını gerektiren bir kabahat işlenmiş olmaktadır.

Banka tarafından birden fazla müşterinin talebine rağmen kredi kartlarının iptal edilmesinin ihmal edilmesi halinde, **kesintisiz (mütemadi) fiille işlenmiş bir kabahat** söz konusudur. Burada müşteri sayısının fazlalığı, kesintisiz (mütemadi) fiille işlenmiş kabahatin sayısının da fazla olduğu şeklinde yorumlanamaz.

Bu örneklerde **ihmali davranışla işlenen bir kabahat** söz konusudur ve sözleşmenin feshedilmesi hususundaki yükümlülüğün yerine getirilmesi ihmal edildiği sürece bu kabahat işlenmeye devam ediliyor demektir. Bu gibi durumlarda sözleşme sayısınca ayrı kabahat işlendiğini kabule imkan bulunmamaktadır. Farklı veya aynı kişiyi ilgilendiren her bir işlemle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilmesini gerektiren bir durumun söz konusu olduğu hallerde, kanunda idari para cezasının her bir işlemle ilgili olarak ayrı ayrı uygulanacağı yönünde açık bir hükme yer verilmektedir. Örneğin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4077 s. Kanunun 6. maddesinin son fıkrası hükmüne istinaden belirlemiş bulunduğu usul ve esaslara aykırı hareket ederek, standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların sözleşme metinlerinden çıkarılmasını ihmal eden satıcı ile ilgili idari yaptırım aynı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiştir. Buna göre, 4077 s. Kanunun "6'ncı madde(si)nin yedinci fıkrası uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere, **aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.**" Buna karşılık 25. maddenin ikinci fıkrasında, söz konusu Kanunun "... 11/A maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında ... belirtilen **yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenlere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.**" hükmü yer almaktadır. **Farklı kişilerle veya aynı kişi ile yapılan birden fazla sözleşmenin yükümlülüklerle aykırılık içeren her biriyle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilecek olsaydı, bunun ilgili kanun metninde açıkça gösterilmiş olması gerekirdi.** Bu itibarla, Kanun metninde bu yönde bir sarahat bulunmamasına rağmen, 5326 s. Kabahatler Kanununun 15. maddesi hükümlerinin yanlış yorumundan hareketle, her bir kişi ile ilgili olarak yapılan sözleşme sayısı esas alınarak ayrı ayrı idari para cezasına karar verilmesi halinde, kanuna aykırılık söz konusudur.

Bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin salt ihmal edilmesi dolayısıyla idari para cezası verildikten sonra, buna rağmen söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesinin ihmal edilmesi halinde, **idari yaptırım kararı verildikten sonraki ihmali davranış ayrı bir kabahat olarak değerlendirilecektir.**

Buna karşılık, **bir yükümlülük yerine getirilmeden işlem yapılması dolayısıyla idari para cezası verilmesinin** öngörüldüğü hallerde, kesintisiz fiille işlenmiş kabahatten söz edilemez. Çünkü bu gibi durumlarda kanun koyucu, salt bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi dolayısıyla değil, bir yükümlülük yerine getirilmeden **işlem yapılması dolayısıyla idari para cezası verilmesini** öngörmektedir. Örneğin, 4077 s. Kanun, kendileri bakımından doğuracağı külfetlerle ilgili olarak tüketiciler bilgilendirildikten sonra mesafeli satış sözleşmesinin akdedilebileceğini emretmektedir (m. 9/A, f. 2). Söz konusu Kanun, kendileri bakımından doğuracağı külfetlerle ilgili olarak bilgilendirilmeden tüketicilerle mesafeli satış sözleşmesi imzalanması halinde, salt bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi dolayısıyla değil, **bir yükümlülük yerine getirilmeden işlem yapılması dolayısıyla idari para cezası verilmesini amirdir** (m. 25, f. 2). Başka bir ifadeyle, bu durumda bir yükümlülüğün salt yerine getirilmesinin ihmali dolayısıyla değil, bir yükümlülük yerine getirilmeden işlem tesis edilmiş (sözleşme imzalanmış) olması dolayısıyla idari para cezası öngörülmektedir. Bu gibi durumlarda kesintisiz fiille işlenmiş kabahatten söz edilemez. Bu itibarla, Kabahatler Kanununun 15. maddesinin ikinci fıkrası hükmü karşısında, gerekli bilgilendirme yapılmaksızın sözleşme imzalanması halinde, imzalanan **sözleşme sayısınca** yükümlülük ihlali ve **ayrı kabahat fiili** bulunduğunu kabul etmek gerekir. Bu gibi durumlarda idari para cezası verilirken **gerçek iktima** kurallarının uygulanması gerekmektedir.

Özellikle ihmali davranışla işlenen kabahatler bakımından uygulamada yaşanan kargaşanın¹³²⁷ önüne geçebilmek amacıyla, Başbakanlık tarafından 18.6.2012

¹³²⁷ **Danıştay 15. Dairesinin 5.12.2011** tarihli ve E. 2011/14474, K. 2011/5005 sayılı Kararının ilişkin olduğu “Dava; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörü tarafından davacı Şirket nezdinde yapılan inceleme sonucunda, davacı Şirketin tüketicilerle kurmuş olduğu sözleşmelerin mevzuata aykırılığının tespiti üzerine, 216 adet sözleşme için toplam 48.772 TL idari para cezası verilmesine ilişkin İstanbul Valiliğinin ... işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 8. İdare Mahkemesince: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kontrolörleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, davacı Şirket tarafından telefon yoluyla gerçekleştirilen mesafeli hizmet satışının, tüketicilerle mesafeli sözleşme akdetmeksizin gerçekleştirildiğinin ve bu şekilde yapılan satışın idari para cezasını gerektiren fiillerden olduğunun tartışmasız olduğu, ancak mevzuata aykırı olarak yapılan satışlar ile **tek bir yükümlülük ihlal edildiğinden tek ceza verilmesi gerekirken**, her bir sözleşmenin ayrı ayrı hesaplanması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukukaayrılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı İdare tarafından, anılan Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun “Mesafeli sözleşmeler” başlıklı 9/A maddesinin birinci fıkrasında, “**mesafeli sözleşmeler**; yazılı, görsel telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir” kuralı yer almıştır.

Öte yandan anılan Kanunun “Cezai hükümler” başlıklı 25. maddesinin ikinci fıkrasında ise, “*4’üncü maddenin altıncı fıkrasında, 5’inci maddede, 6’ncı maddenin altıncı fıkrasında, 6/A*

maddesinde, 6/B, 6/C maddeleri uyarınca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında, 9'uncu maddede, 9/A maddesinde, 10'uncu maddede, 10/A maddesinde, 10/B maddesinde, 11/A maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 12, 13, 14 ve 15'inci maddelerde belirtilen yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenlere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kontrolörü tarafından davacı Şirket nezdinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen ... Rapor uyarınca, Şirketin telefon yolu ile gerçekleştirdiği mesafeli hizmet satış ve uygulamalarında, 4077 s. Kanunun 9/A maddesi uyarınca **akdedilmesi gereken mesafeli sözleşmelerin akdedilmediği**nin tespit edildiği, bu tespit üzerine dava konusu ... (idarî) işlemle 4077 s. Kanunun 9/A maddesinin ihlal edildiği gerekçesi ile, aynı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2009 yılına ait 119 sözleşmenin her biri için 224 TL, 2010 yılına ait 97 adet sözleşmenin her birinin se, 228 TL uygulanmak suretiyle toplam 216 adet sözleşme için 48.772 TL idari para cezası verildiği anlaşılmaktadır.

4077 s. Kanunun amacı; tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak olup; mesafeli satışlarda gerekli şartları taşıyan sözleşmelerin akdedilmesi de Kanunun sayılan amaçlarına ulaşmasını sağlayan araçlar arasında yer aldığı, mesafeli sözleşme kurulmadan yapılan her bir satışta satıcıların cezalandırılması değil, Kanunun bu şekilde gerçekleştirilmeyen satışları önlemeye yönelik olarak tüketicinin korunması olduğu açıktır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan **yükümlülüklerden her birine** aykırı hareket edenlere idari para cezası verileceği düzenlenmiş olduğundan, Kanunun 9/A maddesine aykırılık nedeniyle verilecek (idarî) para cezasında her bir aykırılık için ayrı ayrı ceza verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan; anılan fıkranın, Kanunda yer alan birden fazla maddenin ayrı ayrı ihlaline ilişkin ortak bir yaptırım öngördüğü ve anılan maddelerde tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin tamamının sözleşmelere yönelik olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “*her bir sözleşme*” ifadesi yerine “*her bir yükümlülük*” ifadesinin yer alması, hükmün, aykırılığı tespit edilen her bir sözleşmeye aynı ceza uygulanmasını bertaraf edecek nitelikte kabul edilmesini imkan vermemektedir.

Bu durumda, mevzuata aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için ayrı ceza uygulanmak suretiyle toplam 48.772 TL idari para cezası verilmesine ilişkin (idarî) işlem hukuka uygun bulunduğundan, Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasındaki miktar üzerinden ihlal edilen tek bir yükümlülük üzerinden ceza verilmesi gerektiği gerekçesi ile dava konusu (idarî) işlemi iptal eden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” (Danıştay 15. Daire, **5.12.2011**, E. 2011/14474, K. 2011/5005. Ayrıca bkz. Danıştay 15. Daire, **20.6.2012**, E. 2011/14475, K. 2012/4759).

4077 s. Kanunun 25. maddesi hükmü, redaksiyonu tarafımızca gerçekleştirilen 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla değiştirilmiştir (m. 476). 4077 s. Kanunun 5728 s. Kanunla değiştirilen **25. maddesinin birinci fıkrasında**, 6. maddenin yedinci fıkrasıyla verilen yetkiye istinaden standart sözleşmelere ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere aykırı olarak sözleşme akdeden satıcı veya sağlayıcılara “*her bir sözleşme için*” 100 TL idari para cezası verileceği; buna karşılık **ikinci fıkrada ise**, sayılan madde ve fıkralarda belirlenen “*yükümlülüklerden her birine*” aykırı hareket edenlere 200 TL idari para cezası verileceği, hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenleme ile Kanun koyucu, hangi hallerde **sözleşme sayısının** dikkate alınacağını açıkça belirlemiştir. **Yükümlülük sayısı**, bu yükümlülükleri ihdas eden ilgili mevzuat hükümlerinden hareketle belirlenebilir. 25. maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkraya nazaran 4077 s. Kanunun pek çok maddesine veya fıkrasına atıfta bulunulmak suretiyle, her bir yükümlülük bağlamında 200 TL idari para cezasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır. Her bir yükümlülük bağlamında ihlal, icrai davranışla gerçekleştirilebileceği gibi, ihmalî davranışla da gerçekleştirilebilir. Bir kabahat, mahiyet itibarıyla ancak bir yükümlülük ihlali suretiyle işlenebilir.

tarhinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen 1/638 Esas sayılı **Sermaye Piyasası Kanunu** Tasarısının hazırlık çalışmaları sırasında şahsımın formülasyonu bu Tasarıda yer alan kabahatlerle ilgili olarak **özel bir içtima hükmüne** yer verilmişti:

“Bu Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir idari para cezası verilir ve ilgili hükme göre verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz.” (m. 104, f. 2)¹³²⁸.

Bu hüküm, bilahare 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kabahatler bakımından söz konusu Kanunun 26.6.2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunla (m. 30) değiştirilen 562. maddesine ondördüncü fıkra olarak aynen alınmıştır.

Aktuel çabamız, bu hükmün kabahatler bakımından genel kanun olan 5326 s. Kanunun 15. maddesine yeni bir fıkra olarak eklenmesini sağlamaya yöneliktir.

Kabahatler Kanununun 15. maddesinin ikinci fıkrasına göre, yükümlülük ihlalinin icraî davranışla gerçekleşebileceği kabahatler bakımından, **aynı kabahatin birden fazla işlenmesi hâlinde, her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası** verilecektir. Buna karşılık, kesintisiz fiille ve bu bağlamda ihmalî davranışla işlenebilen kabahatlerde ise, **idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılacaktır**.

Bu düzenleme itibarıyla sorun, **bir yükümlülük ihlalinin hangi hallerde icraî davranışla, hangi hallerde kesintisiz fiille gerçekleştirildiğinin belirlenmesi sorunu** olarak karşımıza çıkmaktadır.

¹³²⁸ Söz konusu hüküm, 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı ile kanunlaşan metinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan redaksiyonla,

“Bu Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi hâlinde, ilgili hükme göre, ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir idari para cezası verilir ve verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz.” (m. 105, f. 2).

olarak değiştirilmiştir.

§23. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları

Kanunda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlenmesine rağmen, bazı şartların gerçekleşmesi durumunda çeşitli mülahazalarla faile ceza verilmemekte ya da cezada indirim yapılmaktadır. Bütün bu hallerde işlenen fiil suç ve dolayısıyla haksızlık oluşturma özelliğini muhafaza etmektedir. Ancak, kişinin ceza hukuku açısından sorumluluğu cihetine gidilmemekte ya da cezasında indirim yapılmaktadır.

Bunlar, *şahsi cezasızlık sebepleri* ya da *cezayı kaldıran şahsi sebepler*dir.

I. Şahsi Cezasızlık Sebepleri

Şahsi cezasızlık sebepleri, suçun icrası sırasında, yani failin *iter criminise* girdiği andan itibaren mevcut olan sebeplerdir¹³²⁹. Meselâ, izlenen suç siyaseti mülahazasıyla, aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerinin malvarlığına karşı işlemiş bulundukları *hırsızlık*, *mala zarar verme*, *güveni kötüye kullanma* ve *dolandırıcılık* gibi suçlardan dolayı cezalandırılmaları cihetine gidilmemektedir (m. 167, f. 1). Ancak, Kanun koyucu, bazı durumlarda failin işlediği suçtan dolayı büsbütün cezalandırılmamasını değil de, cezasında indirim yapılmasını uygun görmektedir (m. 167, f. 2). Bu gibi durumlarda *cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep* söz konusudur.

Somut olayda bir şahsi cezasızlık sebebinin veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebebin varlığının bilinmesine gerek yoktur (m. 21 gerekçesi).

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplerle ilgili olarak yeni TCK'dan ayrıca şu örnekler verilebilir:

a) *Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi* suçunda (m. 165), eşyayı satan kişinin bunun elde edildiği suçu işlemiş veya bu suçun işlenişine iştirak etmiş olması, bu kişi bakımından söz konusu suç bağlamında sadece bir *şahsi cezasızlık sebebi* oluşturmaktadır. Bu eşyanın elde edildiği suçu işleyen kişi, ayrıca ödünç olarak verme, bağışlama ya da satma fiili dolayısıyla cezalandırılmayacaktır.

b) *Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması* suçunun, aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerden birinin malvarlığına karşı işlenmiş olması, bazı hallerde bir *şahsi cezasızlık sebebi* oluşturmaktadır (m. 245, f. 4).

c) *Yalan tanıklık* suçunda, kişinin örneğin “*kendisinin, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşinin soruşturma ve kovuşturmayla uğramasına neden olabilecek bir hususla ilgili olarak yalan tanıklıkta bulunması*” bir *şahsi cezasızlık sebebi* veya *cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep* olarak kabul edilmiştir (m. 273, f. 1).

¹³²⁹ AKBULUT, Genel Hükümler 5. bası, sh. 235 vd.

ç) Kişi, kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak, *suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme* suçundan dolayı cezalandırılmaz (*şahsi cezasızlık sebebi*: m. 281, f. 1).

d) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunun konusunu oluşturan malvarlığı değerini satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişinin, aklama suçunun (m. 282, f. 1) işlenişine iştirak etmiş olması, bu kişi bakımından maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suç bağlamında sadece bir *şahsi cezasızlık sebebi* oluşturmaktadır. Maddenin birinci fıkrasında tanımlanan aklama suçunun işlenişine iştirak eden kişi, ayrıca aklama suçunun konusunu oluşturan malvarlığı değerini bu özelliğini bilerek satın almaktan, kabul etmekten, bulundurmaktan veya kullanmaktan (m. 282, f. 2) dolayı cezalandırılmayacaktır.

e) *Suçluyu kayırma* suçunun, üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi hâlinde, cezaya hükmolunmaz (*şahsi cezasızlık sebebi*: m. 283, f. 3).

f) *Tutuklu veya hükümlüyü ya da suç delillerini bildirmeme* suçlarının, üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi hâlinde, cezaya hükmolunmaz (*şahsi cezasızlık sebebi*: m. 284, f. 4)¹³³⁰.

g) *Taksirle öldürme veya taksirle yaralama gibi taksirli suçlarda* meydana gelen neticenin, “*münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol*” açması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz (*şahsi cezasızlık sebebi*). Ancak, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde verilecek cezada indirim yapılmaktadır (*cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep*) (m. 22, f. 6).

Aynı şekilde, Anayasa’da gerek Cumhurbaşkanı, gerek Milletvekilleri açısından kabul edilmiş olan “*mutlak dokunulmazlık*” halinde bir **şahsi cezasızlık sebebi** söz konusudur (Anayasa, m. 83, 105).

I. Kamu görevlileri görevleri gereği kendilerine yüklenen yükümlülüklerle aykırı davranışta bulunmaları halinde, herkes gibi sorumlu olacaktır. Kamu hukukunda bir kamu görevini üstlenmek, kişi açısından bazı özel yükümlülükleri ifade ettiği gibi, kişinin kamu otoritesi adına bazı yetkileri kullanmasını da gerekli kılar. Dolayısıyla, kamu otoritesi adına yetkiler kullanan bu kamu görevlisinin sorumluluğu da mevcuttur. Kamu otoritesi adına kullanılan yetkiyle doğru orantılı ola-

¹³³⁰ *Özbek*, şahsi cezasızlık sebebine ilişkin örnekler arasında TCK’nın 129. maddesinin üçüncü fıkrasını da zikretmektedir (ÖZBEK, Veli Özer: *Ceza Muhakemesi Hukuku*, Ankara, 2006, sh. 89). Halbuki, TCK’nın 129. maddesinde *özel haksız tahrik hükümlerine* yer verilmiştir (Bu konuda yukarıda “haksız tahrik” başlığı altında yaptığımız açıklamalara bkz.). *Özbek*, kitabının başka bir yerinde ise, karşılıklı hakareti “cezaı kaldıran hal” olarak telakki etmektedir (ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, sh. 683).

rak sorumluluk da artmaktadır (Kural: “*Ne kadar görev varsa, o kadar yetki; ne kadar yetki varsa, o kadar sorumluluk vardır.*”)¹³³¹.

Ancak anayasalarda, Cumhurbaşkanı ve milletvekili gibi belirli kamu görevlilerinin işledikleri bazı fiillerle ilgili olarak cezaî sorumluluklarının olmadığı kabul edilmektedir. Anayasalardaki bu sorumsuzluk hükümlerinin gereği olarak, Cumhurbaşkanı ve milletvekili gibi belirli kamu görevlilerinin işledikleri bazı fiiller suç oluştursa bile cezaî sorumlulukları cihetine gidilememektedir.

Kanunda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlenmesine rağmen, **failin şahsından kaynaklanan** bazı **şartların** varlığı halinde, bu sebeple kendisine ceza verilmemektedir. Bu hallerde işlenen fiil suç ve dolayısıyla, haksızlık oluşturma özelliğini muhafaza etmektedir. Ancak, kişinin ceza hukuku açısından sorumluluğu cihetine gidilmemektedir. Bu hallerden bir kısmı, **şahsî cezasızlık sebepleri** olarak nitelendirilmektedir.

Şahsî cezasızlık sebepleri, **suçun icrası sırasında mevcut** olan sebeplerdir. Meselâ, izlenen suç siyaseti mülahazasıyla, aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerinin malvarlığına karşı işlemiş bulundukları *hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma* ve *dolandırıcılık* gibi suçlardan dolayı cezalandırılmaları cihetine gidilmemektedir (TCK, m. 167, f. 1).

Anayasada milletvekilleri bakımından kabul edilmiş olan “**mutlak dokunulmazlık**” halinde bir **şahsî cezasızlık sebebi** söz konusudur (1982 Any, m. 83).

II. Anayasada, milletvekillerinin meclis çalışmalarında açıkladıkları oy, söz ve düşüncelerinden dolayı *cezaî sorumluluklarının olmadığı* hüküm altına alınmıştır (1982 Any, m. 83, f. 1). Bu duruma, kamu hukukunda **muafiyet, sorumsuzluk, yasama sorumsuzluğu, yasama bağıışıklığı, mutlak dokunulmazlık (Indemnitaet)** denmektedir.

¹³³¹ Bu nedenle, **kamu görevlileri ile ilgili** olarak zaman zaman mevzuatta yer verilen **sorumsuzluk** hükümlerinin pratik bir anlamı bulunmamaktadır.

10.7.2014 tarihli ve 6551 sayılı “**Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun**”un (RG: 16 Temmuz 2014/29062) 4. maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen, bu Kanun “*kapsamındaki görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz*” hükmü kendi içinde çelişkilidir. Şayet kamu görevlisi kanunla kendisine verilen bir görevi yerine getiriyorsa, sorun yoktur. Görevin yerine getirilmesi bir hukuka uygunluk sebebi oluşturduğu için, artık bu durumda sorumluluktan söz edilemez. Aslında bu hüküm, söz konusu Kanun kapsamında kamu görevlilerine tahmil edilen “**yükümlülük**”lerin **hukukiliği noktasında** mevcut **tereddüte** işaret etmektedir.

Aynı yönde bir hükme 22.7.2016 tarihli ve 667 sayılı “**Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname**”nin (RG: 23 Temmuz 2016/29779) 9. maddesinde yer verilmiştir:

“*Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.*”

Milletvekilleri bakımından bu sorumsuzluk **daimî**dir. Yani, kişinin milletvekilliği sıfatı sona ermiş olsa bile; milletvekili olduğu sırada meclis çalışmalarında ki oy, söz ve düşüncelerinden dolayı muafiyet etkisini devam ettirecektir¹³³².

Muafiyetin bir özelliği de, **vazgeçilemez** oluşudur. Muafiyetten yararlanan kişi (milletvekili), meclis çalışmalarında sarf ettiği sözler, açıkladığı düşünceler dolayısıyla yargılanmak istese bile; bu isteği hukukten kabul edilemeyecektir.

Muafiyet bir **şahsî cezasızlık sebebi** olması itibarıyla; işlenen fiil, hukuka aykırılık vasfını devam ettirecektir. Dolayısıyla, muafiyetten yararlanan kişinin cezaî sorumluluğu cihetine gidilemeyecek ise de; tazminat sorumluluğu devam edecektir¹³³³.

Buna karşılık; (*nispî*) **dokunulmazlık (Immunitaet)**, sadece **muhakeme huku**ku açısından etkili olmaktadır. Dokunulmazlık, kişinin milletvekili seçildikten sonra veya milletvekili seçiminden önce işlediği iddia edilen suçlardan dolayı bu sıfatı taşıdığı sürece hakkında sadece belli muhakeme işlemlerinin yapılması açısından bir engel teşkil etmektedir: **Muhakeme engeli**¹³³⁴. Milletvekili seçildikten sonra veya milletvekili seçiminden önce işlediği iddia edilen suçlardan dolayı dokunulmaz olduğu için, milletvekili hakkında *yapılamayacak* muhakeme işlemleri Anayasada şu şekilde tasrih edilmiştir: *tutulma* (yakalama, zorla getirilme), *tutuklanma*, şüpheli veya sanık sıfatıyla *sorguya çekilme* ve *yargılanma* (kovuşturma işlemlerinin yapılması). Yani, milletvekili işlediği fiil dolayısıyla, *prensip olarak*, “*tutulamaz*” (doğrusu yakalanamaz, zorla getirilemez), *tutuklanamaz*, *sorguya çekilemez* ve *yargılanamaz* (1982 Any, m. 83, f. 2). Dikkat edilmelidir ki; milletvekilinin *üzerinin*, *eşyasının* ve *konutunun aranmaya*-

¹³³² Belirtmek gerekir ki, milletvekilleri açısından muafiyetin sözkonusu olduğu bu fiiller, birer düşünce açıklama şeklinden başka bir şey değildir. De lege ferenda (olması gereken hukuk sisteminde) mücerret düşünce açıklaması, prensip olarak, suç teşkil etmez. Ancak, bir düşünce açıklaması, meselâ bir suçu işlemeye azmettirme, tahrik, teşvik veya bir insanın haysiyetine sövmek ya da insanları inançlarından dolayı kınamak şeklinde ise, suç olarak tavsif edilmek gerekir (Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER Adem: *Basın Hürriyeti Kavramı, Basın Yoluyla İşlenen Suçlarda Sorumluluk Rejimi ile Cevap ve Düzeltme Hakkı Üzerine Düşünceler*, Yeni Türkiye, Eylül-Ekim 1996, yıl 2, sayı 11, sahife 272 vd). Fakat, Anayasa’daki mevcut düzenlemeye göre, meselâ televizyondan naklen yayınlanan meclis görüşmelerinde bir milletvekilinin, kürsüden yaptığı konuşmada halkı suç işlemeğe tahrik etmesi veya din, mezheb, ırk itibarıyla birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa teşvik etmesi ya da bir şahsın haysiyetine tecavüz teşkil eden sözler sarfetmesi halinde dahi, muafiyetten yararlanması gerekir; bir başka ifadeyle, ceza hukuku açısından "sorumsuz" telâkki edilmesi gerekir.

¹³³³ Ancak doktrinde medeni hukukçularımız, yasama sorumsuzluğunun bir “hukuka uygunluk sebebi” oluşturduğu ve tazminat sorumluluğunu da ortadan kaldırdığı yönünde görüşler ileri sürmüşlerdir (Bu kaynaklar için bkz. KESKİNSOY, Ömer: *Siyasi Parti Grubu Toplantılarında Sarf Edilen Sözler Bakımından Tazminat Sorumluluğunun Tartışılmasına Dair Yargıtay Kararının Tahlihi*, in: Terazi Aylık Hukuk Dergisi, yıl 4, sayı 34, Haziran 2009, sh. 96, dn. 35).

¹³³⁴ Sorumsuzluk ve dokunulmazlık kavramları arasındaki farklılıklar için bkz. ÖZBUDUN, Ergun: *Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı: Hukuki Mahiyetleri*, in: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 59, Temmuz/Ağustos 2005, sh. 109 vd.

cağı ve telekomünikasyon yoluyla iletişiminin denetlenemeyeceği hususunda Anayasa’da bir hüküm mevcut değildir. Ancak, milletvekiliyle ilgili olarak yakalama kararı veya emri verilmesini yasaklayan Anayasanın milletvekilinin üzerinin, eşyasının ve konutunun aranmasına ve telekomünikasyon yoluyla iletişiminin denetlenmesine izin verdiğini kabule imkan bulunmamaktadır. Buna rağmen, uygulamada oluşabilecek tereddütleri gidermek amacıyla, bu hususlara Anayasada açıklık getirilmesinde yarar bulunduğu düşüncesindeyiz.

Bu muhakeme işlemleri, milletvekilliği sıfatının sona ermesi üzerine yapılabilir. Bu itibarla; dokunulmazlık, milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece bir etki doğurmaktadır. Bu nedenle, kişinin milletvekili seçildikten sonra veya milletvekili seçiminden önce işlediği iddia edilen suçlardan dolayı dokunulmazlığı kaldırılmadığı takdirde, milletvekili sıfatını taşıdığı sürece, hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olsa bile belirli işlemler yapılamayacağı için, **durma kararı** verilmesi gerekmektedir¹³³⁵.

¹³³⁵ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun **26.9.2006** tarihli ve E. 2006/4.MD-157, K. 2006/200 sayılı Kararı, bir ceza muhakemesi müessesesi olan dokunulmazlığın kötüye kullanılması bakımından önemli değerlendirmeler içermektedir:

“Sanık, **müsteşar** olarak görev yaptığı dönemde, **yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak hazırlanan atama önerilerine paraf koyarak bilinçli tarzda onay vermiş**, bu suretle **görevde yetkisini kötüye kullanmıştır**. Anayasa’nın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu maddede yer alan ve Devlete hakim olan ilkelerden birisi olan “demokratik hukuk devleti” ilkesi, hukuka bağlı, istikrarlı bir özgürlük rejimini ifade eder. Anılan ilkenin doğal sonucu, **Devletin tüm etkinliklerinde hukukun egemen olması ve hukuk kurallarına uygun davranılmasıdır**. Yine Anayasa’nın 137. maddesi uyarınca, konusu suç teşkil eden yasaya aykırı emirlerin yerine getirilmesi hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta, sanığın, Bakanın emirlerini yerine getirdiğine ve eyleminde görevde yetkiyi kötüye kullanma kastı olmadığına ilişkin savunması, hukuken itibar edilebilir niteliğe dönüşmemektedir.

Bakanların, ceza yargılaması yönünden siyasi dokunulmazlıktan yararlanmalarının verdiği cesaret ve buyuruculuk yetkisiyle yasaya veya mahkeme kararlarına aykırı dahi olsa birtakım işlemleri, müsteşarlar ve diğer alt görevlerde bulunan kişilere yaptırımları nedeniyle, somut olayda da olduğu gibi, **müsteşarlar adeta Bakan nam ve hesabına yargılanan kişiler konumuna gelmektedir**. Sonuçta bu kimselerin mahkûmiyetleri, **Bakanlardan kaynaklanan yasaya aykırı işlemler** yönünden, caydırıcılıktan uzak ve adaletsiz bir durum yaratmaktadır.

Bu adaletsizliğin giderilebilmesi bakımından, dokunulmazlıktan yararlanan siyasi sorumlular hakkında da suç tarihi (2001 yılında muhtelif tarihler) ve uygulanacak yasa nazara alınmak suretiyle gerek 765 sayılı TCK’nın 107. maddesi gerekse 5237 sayılı TCK’nın 67. maddesi uyarınca, merciünden karar talep edilerek, işlemeye başlayan dava zamanasını durdurulmalıdır. Böylece, kendilerine dokunulmazlık sağlayan siyasi kimlikleri yönteminde sona erdirildiğinde haklarında kamu davası açılmasının yolu açılıp, hukuka aykırı bu ayrıcalıktan yararlanma cesareti ortadan kalkacaktır.

Yukarıda açıklanan demokratik hukuk devleti ilkesinin gerçek anlamda uygulanabilmesi için, soruşturma ve kovuşturma makamlarının, siyasi dokunulmazlıktan yararlanan Bakanların yasaya aykırı işlemleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmasını sağlayacak yasal işlemleri yapmalarının yasal bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.

Bakanın, siyasi konumunun sağladığı dokunulmazlık nedeniyle suç teşkil eden bu atamalarından dolayı yargılanmamış olması, yasaya aykırı bu işlemleri hukuka uygun hale getirmeyece-

Kendisine isnat edilen suç dolayısıyla milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması halinde, milletvekili sıfatını taşısa bile, durma kararı geri alınarak, hakkında başlatılmış olan soruşturma veya kovuşturmayaya devam olunur. Milletvekili ile ilgili olarak dokunulmazlığın kaldırılmasına karar vermeye Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilidir (1982 Any, m. 83, f. 2).

Dokunulmazlığı kaldırılarak, hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturma sonucunda, işlediği kabul edilen **kasıtlı** bir **suçtan** dolayı bir cezaya mahkum olan ve mahkumiyet kararı kesinleşen milletvekilinin, bu mahkumiyetin kanuni neticesi olarak, Türk Ceza Kanununun 53. maddesi hükümlerine göre belli hakları kullanmaktan yasaklanması söz konusu olacaktır. Mahkumiyet halinde altı ihtimal söz konusu olabilir.

Birinci ihtimal: Milletvekili bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilmiştir. Bu durumda, mahkumiyetin kanuni neticesi olarak milletvekilliği sıfatı kendiliğinden sona erer (1982 Any, m. 76, f. 2). Dikkat edilmelidir ki, mahkum olunan bu ceza ertelenmiş olsa bile, milletvekilliği sıfatı sona erer. Çünkü erteleme, aşağıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere, mülga 765 sayılı TCK'dan farklı olarak, yeni TCK'nın 51. maddesinde bir şartlı atıfet müessesesi olarak değil, infaz rejimi olarak düzenlenmiştir.

İkinci ihtimal: Milletvekili Anayasanın 76. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan suçlardan¹³³⁶ herhangi birinden dolayı hapis veya adli para cezasına mahkum edilmiştir. Bu durumda, mahkumiyetin kanuni neticesi olarak milletvekilliği sıfatı kendiliğinden sona erer (1982 Any, m. 76, f. 2).

Üçüncü ihtimal: Milletvekili bir yıldan daha az süreli hapis cezasına (TCK, m. 49, f. 2) mahkum edilmiştir. Anayasanın düzenlemesine göre, bu mahkumiyet, milletvekili seçilmeye engel teşkil etmediği için, bu durumda mahkum olan kişinin milletvekili sıfatı devam eder.

Dördüncü ihtimal: Milletvekili adli para cezasına mahkum edilmiştir. Bu durumda, mahkum olunan adli para cezasına bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu söz konusu değildir ve dolayısıyla, mahkum olan kişinin milletvekili sıfatı devam eder.

Beşinci ihtimal: Milletvekili kısa (bir yıl veya daha az) süreli hapis cezasına (TCK, m. 49, f. 2) mahkum edilmiş ve fakat bu cezası TCK, m. 50 hükümlerine istinaden seçenек yaptırımlardan birine çevrilmiştir. TCK, m. 50, f. 5 hükmü

ği gibi, (müsteşar olan) sanığın bu işlemlerdeki hukuki sorumluluğunu da ortadan kaldırmayacaktır.”

¹³³⁶ Bunlar, “zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları”dır.

karşısında, bu mahkumiyet, milletvekili seçilmeye engel teşkil etmez ve bu durumda mahkum olan kişinin milletvekili sıfatı devam eder.¹³³⁷

Altıncı ihtimal: Milletvekili taksirle işlediği bir suçtan dolayı örneğin üç yıl süreli hapis cezasına mahkum edilmiş ve fakat bu cezası TCK, m. 50 hükümlerine istinaden seçenek yaptırımlardan birine çevrilmemiştir. Bu mahkumiyet, milletvekili seçilmeye engel teşkil etmez ve bu durumda mahkum olan kişinin milletvekili sıfatı devam eder.

Şayet, milletvekili hakkında verilen mahkumiyet hükmü milletvekilliği sıfatını sona erdirmiyorsa, bu hükmün infazı, milletvekilliği sıfatının sona ermesine talik edilir; yani, hakkındaki mahkumiyet hükmü milletvekili sıfatı devam ettiği sürece infaz edilmez. Bu süre zarfında ceza zamanaşımı işlemeyecektir (1982 Any, m. 83, f. 3).

Anayasada, milletvekili hakkında verilmiş olan mahkumiyet hükmünün infazının ertelenmesi halinde **ceza zamanaşımının işlemeyeceği** konusunda açık hüküm bulunmaktadır. Buna karşılık, kendisine yüklenen suç nedeniyle hakkında belirli işlemlerin yapılamaması nedeniyle durma kararı verilerek soruşturma ve kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine talik edildiği durumlarda, milletvekili sıfatı devam ettiği süre zarfında **dava zamanaşımının işlemeyeceği** hususunda Anayasada açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, doktrin ve uygulamamız, Anayasanın 83. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü **geniş yorumlamaktadır**. Buna göre söz konusu hüküm, hem dava zamanaşımını hem de ceza zamanaşımını kapsamaktadır.

Milletvekilinin işlediği bazı fiiller dokunulmazlık kapsamı dışında tutulmuştur (1982 Any, m. 83, f. 2). Buna göre, “*ağır cezayı gerektiren suçüstü hali*”nde bulunan milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapılabilecektir.

“*Ağır cezayı gerektiren*” ve suçüstü halinde işlenen suçun milletvekili sıfatı kazanılmadan önce veya sonra işlenmiş olmasının bir önemi bulunmamaktadır. 5237 s. Türk Ceza Kanununda cezalar bakımından “ağır” ve “hafif” ayırımı kaldırıldığı için, Anayasanın bu hükmünde yer alan “*ağır cezayı gerektiren*” suç ibaresini **ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suç** olarak anlamak gerekmektedir. Suçüstü hali kavramı da 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununun 2. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, “*suçüstü*” halinde işlenen suç ibaresi,

“1. İşlenmekte olan suç,

¹³³⁷ Ancak belirtelim ki, milletvekilinin örneğin **güveni kötüye kullanma** veya **özel belgede sahtecilik** suçundan dolayı mahkum olduğu hapis cezası, TCK, m. 50 hükümlerine istinaden **adli para cezasına** çevrilmiş olsa bile, bu mahkumiyeti dolayısıyla milletvekilliği sıfatı sona erer. Zira Anayasanın 76. maddesinin ikinci fıkrasında sayılmaları sebebiyle, bu suçlardan herhangi biri dolayısıyla, hapis veya para cezası ayırımı yapılmaksızın, salt “hüküm giymiş” olmak, milletvekili seçilme engeli olarak kabul edilmiştir. Fakat, söz konusu suçlardan dolayı mahkum olunan kısa süreli hapis cezası TCK, m. 50’de belirtilen adli para cezası dışındaki sair yaptırımlardan birine çevrilmiş ise, milletvekilliği sıfatı devam eder.

2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,
 3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu,
- ... ifade eder.” (f. 1, bent j).

Keza, “seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14’üncü maddesindeki durumlar” dokunulmazlık kapsamı dışında tutulmuştur. Anayasanın 14. maddesine göre; “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.” Bu maddede herhangi somut bir suçtan söz edilmemektedir. Buna rağmen, zorlama bir yorum yöntemiyle hangi suçların 14. madde kapsamında yer aldığı söylenebilir. Buna göre,

- a) “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan (ve Türk Ceza Kanununda ya da diğer kanunlarda açıkça suç olarak tanımlanan) faaliyetler”,
- b) “Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan” ve Türk Ceza Kanununda ya da diğer kanunlarda açıkça suç olarak tanımlanan faaliyetler,

dolayısıyla **hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra kişinin milletvekili seçilmesi halinde**, bilahare milletvekilliği sıfatını kazanmış olsa bile, başlatılmış olan soruşturma veya kovuşturmaya devam olunur. Bu suçlar nedeniyle yapılmakta olan soruşturma ve kovuşturma çerçevesinde milletvekili yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır. Bu soruşturma ve kovuşturma kapsamında milletvekili, *tutulabilecek* (hakkında yakalama veya zorla getirme emri veya kararı verilebilecek), *tutuklanabilecek*, şüpheli veya sanık sıfatıyla *sorguya çekilebilecek* ve *yargılanabilecektir*.

Suç oluşturan bir fiilin Anayasanın 14. maddesi kapsamına giren faaliyet olarak nitelendirilmesine, soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı veya yargılamayı yapan mahkeme yetkilidir.

Önemle işaret etmek gerekir ki, Anayasanın bu düzenlemesi karşısında, **soruşturma veya kovuşturma konusu suçun 3713 s. Terörle Mücadele Kanununun 3 ve 4. maddelerinde belirlenen terör suçları veya terör amacıyla işlenen suçlardan biri olması halinde, yani terör suçluları hakkında, milletve-**

kili seçilmeden önce soruşturmaya başlanmış olmak kaydıyla, dokunulmazlıktan söz etmek mümkün değildir.

Keza, **terör örgütünün propagandası suçu** da bu istisna kapsamında değerlendirilmelidir (3713 s. K. m. 7, f. 2)¹³³⁸.

Dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek olmaksızın soruşturma ve kovuşturma yapılabilen suçlardan dolayı milletvekilinin bir cezaya mahkum edilmesi ve mahkumiyet kararının kesinleşmesi halinde, bu mahkumiyetin kanuni neticesi olarak, belli hakları kullanmaktan yasaklanması söz konusu olacaktır. Bu durumda yukarıda açıkladığımız mahkumiyete bağlı dört ihtimalden biri söz konusu olabilir¹³³⁹.

¹³³⁸ Ayrıntılı bilgi için bkz. Anayasa Mahkemesi, 1.7.2021, BB. 2019/10634.

¹³³⁹ 20.5.2016 tarihli ve 6718 sayılı Kanunla Anayasa'ya bir geçici madde eklenmiştir (Geçici Madde 20). Buna göre,

“Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.” (birinci fıkra)

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, yetkili merciine iade edilir.” (ikinci fıkra)

Söz konusu madde hükmüne göre, örneğin terör suçları gibi herhangi bir istisna getirilmeden, başta Cumhurbaşkanına ve çeşitli kamu görevlilerine hakaret suçları olmak üzere pek çok suç yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında tutulmaktadır. Bu suçların yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında tutulması, uygulamada, ifade ve sorguya çağrıldığı halde gitmeyen milletvekilli ve hatta anamuhalefet ve muhalefet partileri genel başkanları hakkında zorla getirme ve yakalama tedbirlerinin uygulanması zorunluluğunu ortaya çıkaracaktır.

Başta anamuhalefet ve muhalefet partileri genel başkanları olmak üzere, milletvekilleri hakkında hakaret gibi suçlardan dolayı yapılan soruşturmalarda zorla getirme veya yakalama kararı verilmesi halinde bu kararların uygulaması, ülkemizdeki siyasi istikrar üzerinde önemli bir olumsuz etki meydana getirecektir.

Bu arada 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen “darbe” teşebbüsü sonrası ülkemizde oluşan siyasi atmosferin bir sonucu olarak, Sayın Cumhurbaşkanı bazı siyasi şahsiyetler tarafından kendisine yönelik olarak gerçekleştirilen hakaret fiilleriyle ilgili olarak “bir defaya mahsus af” yetkisini kullandığını beyan etmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanının bu yöndeki açıklaması teknik anlamda bir af yetkisi kullanımı olarak değerlendirilemez. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı şikayetten vazgeçme mekanizması da işletilemez. Keza, söz konusu suç dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı olmakla birlikte, Bakanın verdiği izne dayalı olarak bu suç sebebiyle soruşturma ve kovuşturma başladıktan sonra, artık bu **izin geri alınamaz**.

III. Anayasada 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki düzenlemede, Cumhurbaşkanı bakımından da sorumsuzluk kabul edilmişti. Değişiklikten önceki 105. madde hükmünde, siyasi sorumsuzluğunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı, “vatana ihanet”¹³⁴⁰ dışında, görevi ile ilgili fiillerinden dolayı ceza hukuku bakımından da sorumsuz kılınmıştı.

Anayasanın 6771 sayılı Kanunla değiştirilen 105. maddesi düzenlemesinde ise, **Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu kaldırılmıştır. Buna göre, artık Cumhurbaşkanı işlediği herhangi bir suç sebebiyle sorumlu tutulabilecektir.**

Ancak, Cumhurbaşkanının işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı hakkında soruşturma yapılabilmesi için, **Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararı** gereklidir. TBMM Genel Kurulu kararı olmadan hakkında soruşturma başlatılamayacağı için, bu karar alınıncaya kadar Cumhurbaşkanı yakalanamaz, gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, üzeri ve eşyası aranamaz, konutunda ve işyerinde arama yapılamaz, telekomünikasyon yoluyla iletişimi denetlenemez, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamaz ve sorguya çekilemez. Bu itibarla, **Cumhurbaşkanı, işlediği iddia edilen herhangi bir suç sebebiyle TBMM Genel Kurulunca hakkında soruşturma açılmasına karar verilmediği sürece, dokunulmazdır; yani hakkında şüpheli sıfatıyla herhangi bir soruşturma işlemi yapılamaz.**

Anayasanın 6771 sayılı Kanunla değiştirilen 105. maddesine göre;

“Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.” (birinci fıkra)

“Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.” (ikinci fıkra)

“Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.” (üçüncü fıkra)

¹³⁴⁰ “Vatana ihanet” kavramına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. bu kitabın 12. basısı, sh. 637 vd.

...

“Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı'nın görevi sona erer.” (beşinci fıkra)

“Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.” (altıncı fıkra)

105. madde hükmü **kişinin Cumhurbaşkanı sıfatını kazandıktan sonra ve bu sıfatı taşıdığı süre zarfında** işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak uygulanacak soruşturma ve kovuşturmayla ilişkin özel hükümleri içermektedir. Başka bir ifadeyle, her ne kadar söz konusu 105. maddenin altıncı fıkrası ifadesi aksine bir düşüncüyü benimsediği izlenimi vermekte ise de, kanaatimizce, 105. maddedeki soruşturma ve kovuşturmayla ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için, suç Cumhurbaşkanı'nın göreve başladıktan sonra işlemesi şart değildir.

105. maddedeki soruşturma ve kovuşturmayla ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için, **suçun Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili olması da şart değildir**. Başka bir ifadeyle, **göreviyle ilgili olsun veya olmasın, kişinin cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığı süre zarfında işlediği iddia edilen bütün suçlar** dolayısıyla hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için, TBMM Genel Kurulunun “*üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla*” karar verilmesi gerekir.

Değiştirilen 105. maddede Cumhurbaşkanının “suçüstü” halinde işlediği suçlarla ilgili olarak nasıl bir yol izleneceği konusunda hüküm bulunmamaktadır.

Keza, söz konusu maddede, işlediği iddia edilen suçla ilgili olarak Cumhurbaşkanı hakkında TBMM Genel Kurulunca soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, koruma tedbirlerine başvurulup başvurulamayacağı konusunda da bir açıklık bulunmamaktadır.

Bu durum, özellikle suçüstü halinde koruma tedbirlerine başvurma bakımından **spekülatif** değerlendirmelere ve hatta uygulamalara zemin oluşturabilecek bir mahiyet taşımaktadır.

Cumhurbaşkanının bu göreve seçilmeden önce işlediği iddia edilen suçlar dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma bakımından nasıl bir yol izleneceği konusunda Anayasada hüküm bulunmamaktadır. Kanaatimizce, bu suçlar bağlamında da Cumhurbaşkanının **dokunulmaz** olduğunu kabul etmek gerekir. Bu itibarla, Cumhurbaşkanının bu göreve seçilmeden önce işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle, hakkında yakalama veya zorla getirme emri veya kararı verilemeyecek, üzeri, eşyası ve konutu aranamayacak, tutuklanamayacak, şüpheli veya sanık sıfatıyla ifadesi alınamayacak veya sorguya çekilemeyecek ve yargılanamayacaktır.

Nitekim 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununda, **Cumhurbaşkanının Cumhuriyet savcısı, hakim ve hatta mahkeme tarafından tanık olarak çağırılması-**

na izin verilmemiştir (m. 43, f. 4). Buna göre, bir soruşturma veya kovuşturmada Cumhurbaşkanı tanıklık yapıp yapmamayı kendisi takdir edecektir. Cumhurbaşkanı tanıklık yapmayı kabul etmesi halinde, beyanı Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından konutunda alınabileceği gibi, tanık sıfatıyla yapacağı açıklamaları soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığına, kovuşturma evresinde ise mahkemeye yazılı olarak gönderebilir.

Keza Ceza Muhakemesi Kanununa göre, şüpheli veya sanık sıfatıyla “ifadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma nedeni açıkça belirtilir; **gelmezse zorla getirileceği yazılır.**” (m. 145, f. 1). Cumhurbaşkanı bu sıfatı kazanmadan önce işlediği iddia edilen suçlar dolayısıyla dokunulmaz olduğunun kabul edilmemesi halinde, Ceza Muhakemesi Kanununun 146. maddesi hükümlerine göre zorla getirilebileceği sonucuna ulaşmak gerekir. Ancak, bu yönde bir uygulamanın, Anayasada “**Devletin başı**” olarak kabul edilen ve “**bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eden**” (m. 104, f. 1 ve 2) Cumhurbaşkanlığı göreviyle ve sıfatıyla bağdaştırılması mümkün değildir.

Anayasanın ve Ceza Muhakemesi Kanununun mevcut hükümleri karşısında, **Cumhurbaşkanının bu göreve seçilmeden önce işlediği iddia edilen suçlar bakımından da dokunulmaz** olduğunu kabul etmek, bir zorunluluktur. Ancak, Cumhurbaşkanı bu göreve seçilmeden önce işlediği iddia edilen suçlar dolayısıyla soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin olarak Anayasada açık hüküm bulunmadığı için, milletvekilleriyle ilgili olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Anayasa hükümlerini Cumhurbaşkanı bakımından işletme imkanının bulunmadığını düşünmekteyiz¹³⁴¹.

Bu suçlar bakımından da Cumhurbaşkanı dokunulmaz olduğunu kabul etmemiz karşısında, işlediği ileri sürülen bu suç sebebiyle bu görevi devam ettiği sürece hakkında milletvekili dokunulmazlığında olduğu gibi belirli soruşturma işlemleri yapılamaz belirli koruma tedbirlerine başvurulamaz. Kişinin Cumhurbaşkanlığı sıfatı devam ettiği sürece bu soruşturma derdest olmaya devam etmekle birlikte, bu soruşturma kapsamında hakkında yakalama veya zorla getirme emri veya kararı verilemeyecek, üzeri, eşyası ve konutu aranamayacak, tutuklanamayacak, şüpheli veya

¹³⁴¹ Gözler, seçilmeden önce veya seçildikten sonra işlenmiş olması arasında ayırım yapmaksızın, Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili olmayan suçlarından dolayı **sorumsuzluğunun söz konusu olmadığı**, herkes gibi cezai bakımdan sorumlu olduğu görüşündedir (GÖZLER, Kemal: *Türk Anayasa Hukuku Dersleri*, 5. bası, Bursa, Ocak 2008, sh. 437; aynı yazar: *Anayasa Hukukuna Giriş, Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku*, 11. bası, Bursa, Ekim 2007, sh. 288). Ancak yazar, değişik ülke anayasalarından örnekler göstererek, Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili olmayan suçlarından dolayı **dokunulmaz olduğunu**, yani hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılamayacağını ve bu sıfatı devam ettiği sürece kendisine isnat edilen suç dolayısıyla dava zamanaşımının işlemeyeceğini açıklamaktadır. (GÖZLER, Kemal: *Devlet Başkanları*, Bursa 2001, sh.86 vd.).

sanık sıfatıyla ifadesi alınamayacak, sorguya çekilemeyecek ve yargılanamayacaktır. Dokunulmazlık bir kamu hukuku müessesesi olduğu için, bundan yararlanan kişinin **rızası olsa bile**, hakkında söz konusu işlemler yapılamayacaktır.

Bu nedenle açılan soruşturmada **bekletme kararı verilmesi gerekir**. Kişinin Cumhurbaşkanlığı görevinin sona ermesi halinde, bu suçlar nedeniyle hakkında açılmış olan soruşturmaya kaldığı yerden devam edilebilir.

Cumhurbaşkanının bu göreve seçilmeden önce işlediği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında soruşturma açılmış olsun veya olmasın, Anayasada açık hüküm bulunmadığı için, Cumhurbaşkanlığı görevinin devam ettiği süre zarfında da **dava zamanaşımı işlemeye devam edecektir**.

Cumhurbaşkanının bu göreve seçilmeden önce işlediği iddia edilen suçlar bağlamda üç ihtimal düşünülebilir.

a) Kişinin Cumhurbaşkanı seçilmeden önce herhangi bir görevle bağlantılı olmaksızın kişisel bir suç işlediği iddia edilebilir.

Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle Cumhurbaşkanının dokunulmaz olduğunu kabul etmemiz karşısında, işlediği ileri sürülen bu suç sebebiyle bu görevi devam ettiği sürece hakkında soruşturma açılabilir ve fakat, milletvekili dokunulmazlığında olduğu gibi belirli soruşturma işlemleri yapılamaz belirli koruma tedbirlerine başvurulamaz. Bu nedenle açılan soruşturmada **bekletme kararı verilmesi gerekir**. Kişinin Cumhurbaşkanlığı görevinin sona ermesi halinde, göreviyle bağlantılı olmaksızın işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle hakkında açılmış olan soruşturmaya kaldığı yerden devam edilebilir¹³⁴².

¹³⁴² Bu bağlamda 11. Cumhurbaşkanı Sayın **Abdullah Gül** ile ilgili bir soruşturmada Yargıtay **11. Ceza Dairesinin** vermiş bulunduğu **14.06.2010 tarihli ve E. 2009/16787, K. 2010/7000 sayılı Kararı** göz önünde bulundurma gerekir.

Söz konusu olayda:

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün 1997 yılında milletvekili iken işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılır.

Bu soruşturmada Sayın Gül'ün dokunulmazlığının kaldırılması hususu değerlendirilmek üzere, hakkında Fezleke düzenlenerek, TBMM Başkanlığına gönderilir.

Sayın Gül, TBMM Genel Kurulunca Cumhurbaşkanı olarak seçildiği 28.08.2007 tarihine kadar milletvekili sıfatını taşıdığı için, dokunulmazlıktan yararlanır.

Sayın Gül, Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra, milletvekili sıfatı sona erdiği için, söz konusu fezleke TBMM Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, Sayın Gül'ün milletvekilliği sıfatı sona ermiş olmakla birlikte, Cumhurbaşkanı seçildiği için, sorumsuz olduğundan bahisle, hakkında **kovuşturmaya yer olmadığı kararı** verir.

Bu karara, bir vatandaş tarafından itiraz edilir.

Bu itiraz üzerine, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, soruşturma konusu suç Cumhurbaşkanının görevi ile bağlantılı olmadığı için, sorumsuzluk kapsamında değerlendirilemeyeceği, mevcut Anayasal düzenlemeler itibarıyla Cumhurbaşkanı hakkında göreviyle ilgili olmayan suçlar dolayı-

b) Kişinin Cumhurbaşkanı seçilmeden önce yürüttüğü görevle bağlantılı olan bir suç işlediği iddia edilebilir. Bu suç, örneğin 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınmak suretiyle faili hakkında soruşturma yapılabilecek bir suç olabilir.

Bu ihtimalde de Cumhurbaşkanı hakkında bu görevi devam ettiği sürece herhangi bir soruşturma ve kovuşturma işlemi yapılamaz.

c) Kişinin Cumhurbaşkanı seçilmeden önce yürüttüğü Başbakanlık veya Bakanlık ya da Cumhurbaşkanı yardımcılığı göreviyle bağlantılı olan bir suç işlediği iddia edilebilir. Bu suç sebebiyle ilgili Başbakan veya Bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı hakkında ancak **Meclis Soruşturması** açılabilir ise de, kişi bilahare Cumhurbaşkanı seçildiği için, Cumhurbaşkanı hakkında bu görevi devam ettiği sürece Meclis Soruşturması yapılamaz (Meclis Soruşturması ile ilgili olarak bkz. Anayasanın 6771 s. Kanunla yürürlükten kaldırılan

sayılı **genel hükümlere göre soruşturma yapılması gerektiği** gerekçesi ile, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılmasına karar verir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından bu karara karşı kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur.

Bu talep üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz eden kişinin soruşturma konusu suç bağlamında mağdur veya suçtan zarar gören sıfatını taşımadığı gerekçesi ile, yani yetkisiz kişi tarafından itiraz edilmiş olması sebebiyle **Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının kararının bozulmasına karar** verir.

Bu bozma kararında, asıl soruna ilişkin hiçbir tartışma yapılmamıştır. Bu uyuşmazlıkta asıl sorun, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz eden kişinin soruşturma konusu suç bakımından mağdur veya suçtan zarar gören sıfatını taşıyıp taşımadığı ve vaki itirazın süresinde yapılmış olup olmadığı hususlarından ibaret değildir.

Bu uyuşmazlıkta asıl sorun;

- a) kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesinden önce işlediği iddia edilen suçun, sorumsuzluk kapsamında değerlendirilebilip değerlendirilemeyeceği,
- b) sorumsuzluk kapsamında değerlendirilememesi halinde, Cumhurbaşkanı hakkında bu suç nedeniyle genel hükümlere göre soruşturma ve kovuşturma yapılabilip yapılamayacağı,
- c) bu suç dolayısıyla Cumhurbaşkanı hakkında genel hükümlere göre soruşturma yapılamayacak ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada **hangi hukuki gerekçelerle ne karar verilmesi gerektiği**,

bütün bu tespitlere bağlı olarak,

- d) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararının doğru bir karar olup olmadığı,

hususlarına ilişkin bulunmaktadır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına itirazın yetkisiz bir kişi tarafından yapıldığına dair, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebinde ve Yargıtay 11. CD'nin kararında yer alan değerlendirmeler doğrudur.

Ancak, 11. CD'nin kararında sadece bu hususta değerlendirmede bulunulması ile yetinilmiş olması, asıl sorunla ilgili olarak suskun kalınması, kanaatimizce doğru olmamıştır.

Nitekim, **söz konusu soruşturmaya Sayın Gül'ün cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra kaldığı yerden devam edilmiş ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.**

100. maddesi ve aynı Kanunla değiştirilen 106. maddesinin altı ilâ dokuzuncu fıkraları).

IV. Anayasada 6771 sayılı Kanunla yapılan değişiklik itibarıyla, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları, aynı zamanda milletvekili olamayacaktır: “*Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.*” (m. 106, f. 4, üçüncü cümle).

Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanların görevleriyle ilgili suç işlemleri halinde, haklarında soruşturma yapılabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar vermesi gerekir. Bu itibarla, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları hakkında **görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen bir suç sebebiyle** TBMM Genel Kurulunun “üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilmediği takdirde, **dokunulmazdır**; yani **haklarında şüpheli sıfatıyla herhangi bir soruşturma işlemi yapılamaz**.”

Anayasanın 6771 sayılı Kanunla değiştirilen 106. maddesi hükümlerine göre;

“Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.” (beşinci fıkra ikinci ve üçüncü cümleler)

“Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.” (altıncı fıkra)

“Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.” (yedinci fıkra)

“Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.” (sekizinci fıkra)

“Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.” (dokuzuncu fıkra)

Cumhurbaşkanı yardımcılar ve bakanların görevleriyle bağlantılı olmaksızın işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı milletvekillerine ilişkin dokunulmazlık hükümleri uygulanacaktır:

“Cumhurbaşkanı yardımcılar ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanırlar.”
(Any, 6771 s. Kanunla değişik m. 106, f. 10).

V.Yukarıda da açıkladığımız üzere; dokunulmazlık, belirli bir sıfatı taşıyan kişi hakkında bir **suç** şüphesi dolayısıyla belirli soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılamamasını ifade etmektedir. Dokunulmazlıktan söz edebilmemiz için, belirli bir sıfatı taşıyan kişi ile ilgili olarak belirli bir suç şüphesinin varlığı gereklidir. Bu suç, tabir yerinde ise, “**adli**” bir **suç**tur. Bu itibarla, örneğin disiplin suçu bakımından dokunulmazlık söz konusu olamaz.

765 s. TCK’nın sisteminde kabahatler, bir *suç türünü* oluşturmaktaydı. Dolayısıyla, Anayasanın yasama dokunulmazlığı ile ilgili hükümleri, kabahatleri de kapsamakta idi. Yeni TCK’da ve yeni TCK’nın sistemine uyum amacıyla değişiklik yapılan diğer kanunlarda, daha önce “cürüm” veya “kabahat” türünden suç olarak tanımlanan fiillerden bir kısmı, artık suç olarak değil, suçtan ayrı bir haksızlık türü olarak, yani idari para cezasını gerektiren kabahat olarak tanımlanmıştır. Bu fiiller artık suç olmaktan çıkarıldığı için, Anayasanın dokunulmazlığa ilişkin hükümleri bu fiiller bakımından uygulanamaz.

Ancak, belirli sıfatı taşıyan kişiler tarafından kabahat türünden haksızlıkların işlenmesi halinde nasıl bir yol izleneceği hususunda hukuk sistemimizde yaşanan kargaşayı önlemek için, 5326 sayılı **Kabahatler Kanununa** 31’inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde yeni bir madde eklenmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz:

“Dokunulmazlık ve idari para cezasına ilişkin kararın yerine getirilmesi MADDE 31/A- (1) Taşıdığı sıfat nedeniyle dokunulmazlıktan yararlanan kişilerin işlemiş bulundukları kabahatler dolayısıyla verilen idari para cezasına ilişkin kararların, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre cebri icra yoluyla yerine getirilmesi, dokunulmazlıktan yararlanmayı gerektiren sıfat ortadan kalkıncaya kadar ertelenir. Ancak, bu zaman zarfında yerine getirmeye ilişkin zamanaşımı süresi işlemez.”

II. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler

Cezayı kaldıran şahsi sebepler, suç tamamlandıktan sonra gerçekleşmektedirler¹³⁴³. Başka bir deyişle, suç teşkil eden fiil işlenirken, kişinin cezalandırılması-

¹³⁴³ AKBULUT, Genel Hükümler 5. bası, sh. 235 vd.

nı engelleyen herhangi bir durum mevcut değildir. Ancak, suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkan bazı şartların varlığı durumunda, kişiye hiç ceza verilmemekte ya da cezasında indirim yapılmaktadır. *Cezayı kaldıran ya da cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler.*

Suç tamamlandıktan sonra, etkin pişmanlık (faal nedamet) gösterilebilir. Bu nedamet halinde işlenmiş ve tamamlanmış olan suç işlenmemiş hale irca edilmektedir. Ancak, işlenen haksızlığın neticeleri fail tarafından mümkün olduğunca izale edilmektedir¹³⁴⁴.

Kanun koyucu, bazı suçlar açısından, suç tamamlandıktan sonra, henüz soruşturma başlamadan önce, soruşturma evresinde, hüküm verilmeden önce ve hatta cezanın infazı sürecinde etkin pişmanlık gösterilerek işlenen haksızlığın neticelerinin mümkün olduğunca izale edilmesi veya azaltılması halinde; duruma göre, faile hiç ceza verilmemesini veya cezasında belli bir miktar indirim yapılmasını öngörmektedir.

Yeni TCK'da, *cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep* olarak etkin pişmanlığın düzenlendiği hükümlere şu örnekler verilebilir:

- a) Organ ve doku ticareti açısından (m. 93),
- b) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu açısından (m. 110),
- c) Malvarlığına karşı suçlar açısından (m. 168)^{1345,1346},

¹³⁴⁴ Bu hususta bkz. Ask. Yarg.5. D., 18.2.1987, 99/88 (Ask. Yarg. KD, 6(1990), sh. 73).

¹³⁴⁵ "TCK'nın 168. maddesinde düzenlenen "etkin pişmanlık" hükmünün uygulanabilmesi için, maddede sınırlı bir şekilde sayılan suçların işlenmesi halinde, **failin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi** gerekmektedir.

... 5237 sayılı TCY'nın 168. maddesi tazmininden çok "pişmanlık" esasına dayanmaktadır.

Yasa koyucunun, 5237 sayılı TCY'nın 168. maddesinde, "tek başına iade ve tazmine" değil, "pişmanlık sonucu olan iade ve tazmine" önem verdiği madde ile ilgili Meclis Komisyonunda yapılan görüşmelerde kullanılan ifadelerden açıkça anlaşılmaktadır.

Bu açıklamaların sonucu olarak; iade ve tazminin cebri icra yoluyla gerçekleştirilmesi, zararın failin rızası hilafına veya ondan habersiz olarak üçüncü kişilerce giderilmesi, failin yakalanmamak için kaçarken atması sonucu eşyanın ele geçirilmesi, kaçarken yakalanan failin üzerinde ele geçmesi gibi hallerde failin gerçek anlamda pişmanlığından söz edilemeyeceğinden 5237 sayılı TCY'nın 168. maddesinin uygulanma koşulları oluşmayacaktır. Buna karşın, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için *mağdurun uğradığı zararın aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi* koşulu yerine getirilirken duyulan pişmanlığın mutlaka sözle ifade edilmesi zorunluluğu bulunmayıp, söz ve/veya davranışlar yoluyla da ifade edilmesi olayın özelliğine göre olanaklı olabilecektir." CGK, **27.5.2008**, E. 2008/11-127, K. 2008/147. Ayrıca bkz. CGK, **27.10.2009**, E. 2009/6-132, K. 2009/251; CGK, **26.10.2010**, E. 2010/6-173, K. 2010/208; CGK, **27.12.2011**, E. 2010/6-255, K. 2011/294; CGK, **14.2.2012**, E. 2011/6-195, K. 2012/40; CGK, **8.5.2012**, E. 2011/13-474, K. 2012/188; CGK, **22.5.2012**, E. 2011/1-430, K. 2012/203; CGK, **9.4.2013**, E. 2013/6-143, K. 137.

¹³⁴⁶ "İştirak halinde işlenmiş suçlarda fail, yardım eden veya azmettiren suç ortaklarından birinin mağdurun zararını tamamen gidermesi halinde, artık giderilmesi gereken bir zarar bulunmadığından zararı gidermeyen diğer suç ortakları yönünden etkin pişmanlık müessesesinin uygulanması için "iade ve tazmin" şartı aranmayacaktır. Ancak TCK'nın 168. maddesi tazmin-

- d) İmar kirliliğine neden olma açısından (m. 184, f. 5),
- e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma açısından (m. 192),
- f) Parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları açısından (m. 201),
- g) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu açısından (m. 221)¹³⁴⁷,

den çok pişmanlık esasına dayandığından zararı gidermeyen diğer suç ortaklarının en azından pişmanlıklarını ya da iade ve tazmine rıza gösterdiklerini ortaya koyacak söz veya davranışlarda bulunmaları gerekmektedir.”: CGK, 29.3.2016, E. 2015/13-517, K. 2016/154.

Etkin pişmanlık, duruma göre cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren bir şahsi sebeptir. Birden fazla kişinin iştirakiyle işlenen suçlarda suç ortaklarından birinin etkin pişmanlık göstermesi halinde, TCK, m. 40, f. 1, ikinci cümle gereğince, bu etkin pişmanlıktan sadece bu suç ortağı yararlanır. Bu itibarla, somut olayda zararın tazmininin sadece bir suç ortağının karar ve inisiyatifıyla mı, yoksa suç ortaklarının müşterek kararıyla mı gerçekleştiğinin araştırılması gerekir. Burada önemli olan, tazmin amaçlı paranın kimin cebinden çıktığı değil, tazmin yönündeki iradenin oluşumu ve bunun hayata geçirilmesine katkıdır. Bkz. Yargıtay 6. CD, 27.1.2021 tarihli ve E. 2020/4984, K. 2021/1044. Bu Kararına konu teşkil eden olayda G ve T birlikte hırsızlık suçu işlerler. Suç ortaklarından G pişmanlık duyarak mağdurun uğradığı zararı, haklarında hırsızlık suçundan dolayı düzenlenen iddianamenin kabul edildiği gün giderir.

Bu olay bakımından üzerinde durulması gereken esas sorun şudur: İddianamenin kabul edildiği tarih itibarıyla etkin pişmanlık gösterilmesi halinde, fail hakkında soruşturma evresinde pişmanlık hükümlerini mi yoksa kovuşturma evresinde pişmanlık hükümlerini mi uygulamak gerekir?

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, bu sorunu, “*tam bir muhakeme ve ispat sorunu*” olarak değerlendirmiştir. Daire kararına göre;

“Ceza muhakemesine egemen olan ilkelerden birisi de, ‘şüpheden sanığın yararlanması’dır. Zararın giderilmesi keyfiyeti, iddianamenin kabul edildiği 09.04.2015 tarihinde gerçekleşmiş olmakla, etkin pişmanlığın birkaç dakika da olsa iddianamenin kabulünden önce vuku bulması ihtimal dahilindedir. Bu itibarla, şüpheden sanığın yararlanması ilkesi uyarınca, etkin pişmanlığın soruşturma evresinde gerçekleştiğini kabul etmek gerekir.”

¹³⁴⁷ “5237 sayılı TCK’nın çeşitli maddelerinde şahsi cezasızlık hali ile cezanın kaldırılmasını veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler öngörülmüştür. *Şahsi cezasızlık nedenleri suçun işlendiği anda* var olan sebeplerdir. Örneğin, izlenen suç siyaseti gereği aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerinin malvarlığına karşı işlemiş bulundukları hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık gibi suçlardan dolayı cezalandırılmaları yoluna gidilmemektedir. (167/1 m.) Yasa koyucu, bazı durumlarda da işlediği suçtan dolayı failin cezasında indirim yapılmasını yeterli görmektedir. (167/2. m.) *Cezanın kaldırılmasını ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi nedenler ise suç tamamlandıktan sonra* gerçekleşmektedir. Bu halde, suçu oluşturan fiil işlenirken kişinin cezalandırılmasını engelleyen bir durum mevcut değildir. Ancak suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkan bazı koşulların varlığı nedeniyle kişiye ya hiç ceza verilmemekte ya da cezasında indirim yapılmaktadır. 5237 sayılı TCY’nın suç örgütü mensuplarının etkin pişmanlığını düzenleyen 221. maddesinin değişik fıkralarında ise, birbirinden farklı koşullarla, cezanın kaldırılmasını veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi haller kabul edilmiştir.

Şahsi cezasızlığı (TCY’nın 22/6, 167/1, 245/4, 283/3 ve 284/4. maddeleri), cezanın kaldırılmasını gerektiren şahsi sebepleri (TCY’nın 93/1, 184/5, 192/1-2-4, 201, 221, 254, 274/1, 281/5 ve 316/2. maddeleri) veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi nedenleri

- h) Zimmet suçu açısından (m. 248),
- i) Rüşvet suçu açısından (m. 254),
- j) İftira suçu açısından (m. 269)¹³⁴⁸,

(TCY'nın 93/2, 110, 168, 192/3, 248, 269, 274/2-3, 281/3, 289/2, 293 ve 297/4. maddeleri) düzenleyen yasa normlarında öngörülen koşulların oluşup oluşmadığı yargıç tarafından her somut olayda ayrı ayrı saptanacaktır. Yargıcın bir yasa normunun uygulanıp uygulanmayacağından ibaret ve objektif olan bu değerlendirmeyi yaparken yanılması, uygulanmaması gereken bir kuralın uygulanması veya uygulanması gereken bir kuralın uygulanmaması sonucunu doğuracaktır ki, bu durumda "hukuka aykırılık" söz konusu olacaktır. **Şahsi cezasızlık veya cezanın kaldırılmasını gerektiren şahsi sebebi saptayan yargıç, fail hakkında ceza verilmesine yer olmadığını kararlaştırmak zorundadır; bu halde takdir kullanımından bahsedilemez. Cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebebin varlığını yine hukuki bir değerlendirme ile saptadığında ise, cezada belli bir indirim yapacaktır. İşte bu aşamalarda sadece yasada belirli hadler arasında indirim öngörüldüğü hallerde, bu indirim miktarının belirlenmesi işlemi bir takdir hakkının kullanımını gerektirmektedir.**

Somut olayda uygulanıp uygulanmayacağı (tartışma konusu) edilen 5237 sayılı TCK'nın 221. maddesinin 2. fıkrası;

"Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenmesine iştirak etmezsiniz, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında ceza-ya hükmolunmaz."

şeklinde olup; bu madde uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için aranan **iki koşul**, örgüt üyesinin **gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi** ve **örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine katılmamış olmasıdır.**

Şu durumda, davayı gören yargıç, her ikisi de objektif nitelikte olan bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini, genel hukuk bilgisi ile yaşam ve meslek deneyimlerini kullanarak saptayacak, koşulların gerçekleştiğinin belirlenmesi halinde ise faile örgüt üyesi olmak suçundan ceza verilmeyecektir. Bu hususta yargıcın "takdir" kullanamayacağı açıktır. Başka bir deyişle, 5237 sayılı TCK'nın 221. maddesindeki koşullar gerçekleşmesine rağmen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamış olması halinde "uygulanması gereken bir hukuk normunun uygulanmaması" biçiminde gerçekleşen bir hukuka aykırılık söz konusudur." CGK, **23.06.2009**, E. 2009/9-30, K. 2009/177.

¹³⁴⁸ Kanunda, bir kişiye suç isnad edildikten sonra pişmanlık duyularak iftiradan rücu edilmesi halinde failin cezasında belli oranlarda indirim yapılması hükmüne yer verilmiştir (m. 269). Bu itibarla, söz konusu hüküm, suç tamamlandıktan sonra faal nedamet halini öngören bir hükümdür ve failin bu nedenle sadece cezasında indirim yapılmasını amirdir.

Bu maddedeki "soruşturma" ifadesini, kendisine suç isnad edilen kişi hakkında bu nedenle herhangi bir soruşturma işleminin yapılması olarak anlamak gerekir. Bu itibarla; Yargıtay'ın şu kararındaki görüşe iştirak etmek mümkün değildir:

«Aleyhinde isnatta bulunan şahıslar hakkında takipsizlik kararı verilmiş olmasına göre, takibat yapılmamış sayılacağından, sanıkların gerçeğe dönmeleri nedeniyle cezanın altıda birine hükmedilmesi gerekirken, üçte ikisinin indirilmesi suretiyle fazla ceza tayini ... bozmayı gerektirmiş»tir: 4. CD., 30.4.1985, 3630/3924 (YKD, Ekim 1985, sh. 1557).

İftiradan rücu, kendisine suç isnad edilen kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilinceye kadar mümkün olmalıdır. Kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verildikten sonra, gerçek ortaya çıktığı için; iftiradan rücu edilmesi dolayısıyla failin cezasında bir indirim yapılmaması gerekir.

Kendisine isnad edilen suç dolayısıyla kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmişse; mahkûm olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar faili iftirasından rucua teşvik maksadıyla, cezasında

- k) Yalan tanıklık suçu açısından (m. 274),
- l) Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu açısından (m. 281, f. 3),
- m) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu açısından (m. 282, f. 6),
- n) Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu açısından (m. 289, f. 2),
- o) Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu açısından (m. 293),
- p) İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçu açısından (m. 297, f. 4),
- r) Suç için anlaşma suçu açısından (m. 316, f. 2).

III. Ortak Özellikleri

Gerek şahsi cezasızlık sebebinin gerek cezayı ortadan kaldıran şahsi sebeplerin ortak özelliği, bu sebeplerin varlığı durumunda işlenen fiilin suç niteliğinde ve haksızlık muhtevasında herhangi bir değişiklik ve azalma meydana gelmemesidir.

belli oranda indirim yapılması gerekmektedir (4. CD. 16.5.1984, 3524/3665: YKD, Mart 1985 sh. 429). Nitekim, yeni TCK’nda aynı yönde düzenleme yapılmıştır (m. 269, f. 3, bent c).

Dikkat edilmelidir ki; bir başkasına suç isnad eden kişinin iftira suçunu işlediğinden bahisle kendi aleyhine dava açıldıktan sonra, iftirasından rücu etmesinin mahkûm olacağı ceza üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.

Nitekim, CGK., 8.7.1985, 4-141/435 (YKD, Aralık 1985, sh. 1831 vd.). Ancak, Yargıtay’ın şu kararındaki görüşe iştirak etmiyoruz:

«İftira suçundan sanık S’nin ... TCK’nın 285. maddesi uyarınca ... cezalandırılmasına dair Sungurlu Asliye Ceza Mahkemesinden verilen hükmü, ... temyizi üzerine, inceleyen *Özel Daire*; “oluşa, delillere ve kabule göre; S’nin duruşma sırasında alınan ifadesinde isnadından rücu ettiği anlaşıldığı halde; TCK’nın 285. maddesinin son fıkrası ile cezasından indirim yapılması gerektiğinin düşünülmemesi” gerekçesi ile; bozulmasına karar vermiştir.

Mahallî Mahkeme ise; “S’nin duruşmadaki ifadesinde, açıkça isnadından rücu eder anlamına gelecek ve iftira ettiğini kabul eder mahiyette sözler bulunmadığı” gerekçesi ile önceki kararında direnmiştir.

İncelenen dosyaya ve mevcut delillere göre; S’nin, mülkiyeti kendisine ait otomobili 501.000 liraya M’ye tanık huzurunda satarak teslim ettiği; buna rağmen aradan birkaç gün geçtikten sonra, çocuklarının baskısı ile satıştan caydığı; otomobilini geri almak için M’ye gezip dolanması ve sonra da geri getirmesi için verdiğini iddia ederek C. Savcılığına şikâyetle bulunduğu; yapılan tahkikat sonucunda emniyeti suistimal suçunun unsurları oluşmadığı (tespit edildiği için) M hakkında takipsizlik kararı verildiği; bu defa M’nin şikâyeti ile S hakkında iftira suçundan kamu davası açıldığı ve bu davanın duruşması sırasında S’nin “*iftira suçunu kabul etmem; ben M ile arabamı kendisine 505.000 liraya satmam için anlaştık; bu hususta senet yaptık; arabayı kendisine verdim; fakat, sonradan vazgeçtim; çocuklarım razı olmadı; (kendisini) aradım, bulamadım; bu durum karşısında C. Savcılığına şikâyet etmeğe mecbur kaldım*” dediği görülmüştür.

S, kendisine ait aracı müştekiye satarak teslim ettiğini duruşmada kabul ettiğine göre; bu husus ilk isnadından rücu ettiğini açıkça gösterir niteliktedir. S’den ayrıca “iftira etmişim” tarzında bir söz kullanmasını beklemek yasaya uygun bir yorum sayılmaz. S hakkında TCK’nın 285/son maddesinin uygulanması gerekir. Bu nedenle direnme kararının bozulmasına karar verilmelidir.» CGK, 25.10.1982, 4-332/387 (YKD, Ocak 1983, sh. 109 vd.; Savaş/Mollamahmutoğlu II, sh. 2658/2659).

Bununla bağlantılı diğer bir özellik ise, iştirak halinde işlenen suçlarda, bu sebeplerin varlığı halinde bunun diğer suç ortaklarına sirayet etmemesidir.

Nitekim, Yargıtay da aynı görüşü benimsemiştir:

Bir Milletvekili tarafından Meclis müzakereleri sırasında emekli bir albay hakaret mahiyeti arzeden sözler sarfetmiş olup; bu sözler aynen ... Gazetesinde yayınlanmıştır.

Anayasanın Milletvekillerine dokunulmazlık statüsü kazandıran hükmü; “şahıslara hakaret niteliğinde olan sözleri, haber hüviyet ve hususiyetinden ve bunun hududundan ayrılarak (özel) bir maksatla yayınlayanlar(a) ... ceza sorumluluğu terettüp etmeyeceği (şeklinde) yorumla”namaz. Belirtilen nedenlerle; her ne kadar Milletvekili olan şahsın hakaret teşkil eden sözleri dolayısıyla cezaî sorumluluğu cihetine gidilemeyecek ise de; mezkûr sözleri haber niteliği taşımayan bir surette gazetede aynen yayınlayan kişi cezaen sorumlu tutulmalıdır¹³⁴⁹.

Kararda da kabul edildiği üzere, muafiyet, bir *şahsi cezasızlık sebebidir*. İşlenen fiil esas itibarıyla bir suç teşkil ediyorsa; milletvekili açısından muafiyetin mevcudiyeti, bu fiilin haksızlık ve dolayısıyla suç vasfını ortadan kaldırmayacaktır. Her ne kadar muafiyetten yararlanan kişinin cezaî sorumluluğu cihetine gidilemeyecek ise de; *bağlılık prensibi* gereğince, bu kişiyi muafiyet kapsamına giren bir fiili işlemeye azmettiren kişinin cezaî sorumluluğu cihetine gidilebilecektir.

Bir kitle iletişim aracında bir husus haber konusu yapılırken güdülen amaç, kamunun bilgilendirilmesini sağlamaktır. Haber verme hürriyetinin sınırlarından birini, bu amaç teşkil etmektedir. Buna karşılık, bir milletvekilinin “meclis çalışmaları” kapsamı içinde belli bir şahısla alâkalı olarak şahsiyet haklarına tecavüz teşkil eden sözler sarfetmesini fırsat telâkki ederek, bu sözleri “haber” olarak aynen yayınlamak; bu hürriyet kapsamında mütalâa edilemez. Bu itibarla, Kararda yer verilen görüşü doğru telâkki etmekteyiz.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, gerek şahsi cezasızlık sebeplerinden gerek cezayı kaldıran şahsi sebeplerden birinin somut olayda varlığı halinde kişinin, sadece cezaî sorumluluğu cihetine gidilemeyecektir. İşlenen fiil, haksızlık ve dolayısıyla, suç teşkil etme özelliğini devam ettirmektedir. Hatta, kişi işlediği bu suç dolayısıyla kusurlu bulunabilir. Dolayısıyla, şahsi cezasızlık sebebinin veya cezayı kaldıran şahsi sebebin mevcut olduğu hallerde kişi hakkında verilmesi gereken karar, beraat kararı olmamalıdır. Beraat kararı, kanaatimizce, ancak bir haksızlığın söz konusu olmadığı durumlara, yani hadisede en azından bir hukuka uy-

¹³⁴⁹ 4. CD., 24.1.1964, 5841/165 (Önder/Özek: Ceza Hukuku Pratik Çalışma Gereçleri, İstanbul, 1969, sh. 89/90).

gunluk sebebinin mevcut olduğu hallere münhasır kılınmalıdır. Çünkü, bu hallerde kişi haklıdır ve kendisine hiçbir hukuki müeyyide tatbik edilemez. Beraat ("*berâet*"), bir haksızlık iddiasından temiz, ilişiksiz çıkmayı, aklı, arılığı, akanmayı ifade etmektedir^{1350,1351}. Nitekim, yeni Ceza Muhakemesi Kanununun 223'üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre;

"İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen;

a) Etkin pişmanlık,

b) Şahsi cezasızlık sebebinin varlığı,

...

Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir."

IV. Objektif Cezalandırılabilme Şartları

Objektif cezalandırılabilme şartları, işlenen fiilin hukuka aykırılık vasfı ve haksızlık içeriği üzerinde herhangi bir etkisi olmayan olgulardır. Bu olgular, haksızlığın oluşmasını etkilememektedirler. Başka bir deyişle, işlenen fiil haksızlık oluşturma özelliğini taşımakla birlikte, bu şartlar gerçekleşmediği sürece, fiil suç oluşturmamakta ve dolayısıyla, kişiye ceza verme imkânı bulunmamaktadır¹³⁵². Objektif ceza-

¹³⁵⁰ Alman Hukukunda, kusursuzluk halinde dahi "*Freispruch*" kararı verilmektedir (Bkz. ROXIN, Claus: *Strafverfahrensrecht*, 20. Auflage, München, 1987, sh. 303). Ancak, belirtmek gerekir ki, anlam muhtevası itibarıyla, "*Freispruch*", beraat kavramıyla eş anlamlı değildir; beraat kavramı, daha manidardır.

¹³⁵¹ Muafiyet halinde, Kunter, suçun teşekkül etmediğinden bahisle, "beraat" kararı verilmesi gerektiği fikrindedir (KUNTER, no. 40, no. 145 dn. 25). Halbuki bu durumda sadece cezaya hükmedilmemelidir. Yani, muafiyet halinde de işlenen fiil haksızlık teşkil etmekte ve fail bu fiil dolayısıyla kusurlu telâkki edilebilmektedir. İlginçtir ki; Tekinay, milletvekili muafiyetini bir "*Hukuka uygunluk sebebi*" olarak yorumlamaktadır (TEKİNAY, Selâhattin Sulhi: *Borçlar Hukuku*, cilt I, 5. bası, İstanbul, 1985, sh. 655). Bu fikrin kabul edilmesi, hukuken mümkün değildir.

Kunter, daha da ileri giderek, işlenen haksızlıktan dolayı kişinin kusurlu telâkki edilmesine rağmen, *cezalandırılabilirlik için Kanunun aradığı sair şartların gerçekleşmediği durumlarda* da beraat kararının verilmesi gerektiği fikrindedir (KUNTER, no. 145). Meselâ *objektif cezalandırılabilme şartının* arandığı suçlarda, bu şart gerçekleşmese dahi, işlenen fiil haksızlık ve dolayısıyla, suç vasfını devam ettirmektedir (DÖNMEZER/ERMAN I, no. 456). Ancak, izlenen suç siyaseti mülâhazalarıyla, sözkonusu şartın gerçekleşmediği durumlarda işlenen bu haksızlık nedeniyle failin cezalandırılmasına ihtiyaç hissedilmemektedir. Bu itibarla, sözkonusu durumlarda kişinin sadece cezalandırılmasından sarfınazar edilmelidir ve, kanaatimizce, fail lehine beraat kararı verilmemelidir (aksi kanaat, KUNTER, no. 40, 145; DÖNMEZER/ERMAN I, no. 461).

¹³⁵² Bu itibarla, objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmediği durumlarda, haksızlık oluştursa bile, fiil suç olma özelliğini henüz kazanmadığı için, CMK'nın 223. maddesinin ikinci fıkrasının a bendi hükmü gereğince, fail hakkında **beraat** kararı verilmesi gerekir.

Buna karşılık, objektif cezalandırılabilme şartı gerçekleşmediği takdirde, fiilin suç olma özelliğini taşıdığı ve fakat bu durumun failin sadece cezalandırılabilirliği üzerinde etkili olduğu

landırılabilme şartları, aslında *cezalandırılabilirliğin alanını daraltan* bir fonksiyon icra etmektedir.¹³⁵³ Objektif cezalandırılabilme şartı, suçun maddi unsurlarından farklı olarak, kast kapsamında değildir. Başka bir ifadeyle, suçun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleştiğinin fail tarafından bilinmesi gerekmektedir. Buna karşılık, işlenen suç bakımından objektif cezalandırılabilme şartı gerçekleşmiş ise, failin cezalandırılabilmesi için bu şartın gerçekleştiğini bilmesi gerekmemektedir.

Örneğin, mağdurun gıyabında işlenen hakaret suçundan dolayı failin cezalandırılabilmesi için; fiilin, toplu veya dağınık halde olan en az üç kişiyle *ihtilat* ederek (iletişim kurarak) işlenmesi gerekir. “*Bir veya iki kişiyle ihtilat ederek de mağdura hakaret edilebilir. Bu gibi durumlarda da esasında bir haksızlık gerçekleşmektedir. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince, gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, mağdurun gıyabında en az üç kişiyle ihtilat edilerek, yani en az üç kişi muhatap alınarak hakaretin yapılması şart olarak aranmıştır.*”¹³⁵⁴ Bu itibarla, mağdurun gıyabında hakaretin toplu veya dağınık halde olan en az üç kişiyle ihtilat ederek (iletişim kurarak) işlenmesi, bu suç bakımından bir objektif cezalandırılabilme şartını oluşturmaktadır¹³⁵⁵.

Keza, yeni TCK’nın sisteminde, kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olan icrai veya ihmali davranışı ile, a) belli bir kişinin mağduriyetine veya b) kamunun zararına neden olması ya da c) bir kişiye haksız bir menfaat sağlaması halinde, hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dolayı mahkûmiyet kararı verilebilecektir (m. 257, f. 1 ve 2). Bu itibarla, görevinin gereklerine aykırı hareket eden kamu görevlisi hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dolayı mahkûmiyet kararı verilebilmesi için, bu *objektif cezalandırılabilme şartlarının* birinin, somut olayda gerçekleşmesi gerekir^{1356,1357}.

görüşünde olan yazarlar ise, bu durumda fail hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı kararı” verilmesi gerektiği fikrindedirler (Bkz. KANGAL, Zeynel T.: *Cezalandırılabilirliğin Objektif Koşulları*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LXVIII, sayı 1-2, yıl 2010, sh.156). Ancak, bu görüşte olan yazarlardan Kangal, CMK’nın 223. maddesinin dördüncü fıkrasının hangi bendi hükmü gereğince bu kararın verileceği hususunda herhangi bir açıklama yapmamaktadır. Bu görüşün doğru olmadığını düşünmekteyiz. Nitekim uygulamamız, görevi kötüye kullanma suçunda aranan objektif cezalandırılabilme şartlarının gerçekleşmemesi halinde, doğru olarak, fail hakkında **beraat** kararı verilmesi yönünde gelişmiştir.

¹³⁵³ Objektif cezalandırılabilme şartlarına esas itibarıyla ilgili suç tanımında yer verilmektedir. Ancak Yargıtay bazı suç tanımlarıyla bağlantılı olarak cezalandırılabilirliğin alanını daraltmak için, içtihat yoluyla da objektif cezalandırılabilme şartı ihdas edebilmektedir. Yargıtay’a göre, TCK, m. 206’da tanımlanan “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçunun oluşabilmesi için, kişinin örneğin kimliğine ilişkin olarak yalan beyanına istinaden resmi belgenin düzenlenmiş olması gerekir: Yargıtay Ceza Genel Kurulu, **28.11.2019**, E. 2015/15-489, K. 2019/682.

¹³⁵⁴ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 534 vd.

¹³⁵⁵ DEMİRBAŞ, Genel Hükümler [5], sh. 19; KANGAL, İÜHFM, LXVIII, sh.160; AKBULUT, Genel Hükümler, 5. bası, sh. 231 vd.

¹³⁵⁶ TCK’nın 257. maddesinde değişiklik yapan **8.12.2010 tarihli ve 6086 sayılı Kanuna** ilişkin Teklifin **Gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir (TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 565):

Yeni TCK'dan objektif cezalandırılabilme şartına ilişkin olarak ayrıca şu örnekler gösterilebilir:

a) Failin *hileli iflâs* veya *taksirli iflâs suçlarından* dolayı cezalandırılabilmesi için, somut olayda iflasa karar verilmelidir (m. 161, 162).

b) Failin *mal veya hizmet satımından kaçınma* suçundan dolayı cezalandırılabilmesi için, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak suretiyle kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekir (m. 240).

c) *Somut tehlike suçlarında* tehlikeye sebebiyet veren fiilin suç oluşturabilmesi ve dolayısıyla, failin cezalandırılabilmesi için, somut tehlikenin gerçekleşmesi gerekir (m. 170 [f. 1], 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 216, 217, 220, 319).

Somut tehlike suçlarında, icra edilen kanunî tarife uygun fiilin suçun konusu açısından **somut** bir **tehlike** meydana getirmesi, bu suçlar açısından bir unsur olarak¹³⁵⁸ değil, bir cezalandırılabilme şartı olarak anlaşılmalıdır. Bu tür suçlarda kanunî tarife uygun fiilin işlenmesiyle bir haksızlık gerçekleşmektedir. Bu itibarla, kanunî tarife uygun fiil, başlı başına bir haksızlık teşkil etmektedir. Bu haksızlığın oluşumu için gerçekleştirilen fiilin suçun konusu açısından somut bir tehlikeye sebebiyet vermesi gerekmez. Ancak, bu tür fiiller dolayısıyla ceza hukukunun müdahalesi, somut bir tehlikenin meydana gelmesi halinde mümkün olacaktır. Bu itibarla, somut tehlikenin oluşumu, söz konusu suçlar bakımından bir *objektif cezalandırılabilme şartı* olarak anlaşılmalıdır.¹³⁵⁹

“Türk Ceza Kanununun 257’nci maddesinde düzenlenmiş olan görevi kötüye kullanma suçu ile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240’ıncı maddelerinde düzenlenen suçlar tek bir madde altında toplanmıştır. Mevcut düzenlemede görevi kötüye kullanma suçu, genel ve tamamlayıcı bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, görevin gereklerine aykırı davranışın başka bir suçu oluşturmadığı hallerde söz konusu suç olacaktır. Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki düzenlemelerden farklı olarak, bu suçun oluşabilmesi için, **objektif cezalandırılabilme şartı** olarak, görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olunması ya da kişilere haksız menfaat sağlanması gerekmektedir.”

¹³⁵⁷ ÖZGENÇ, İzzet: *İrtikâp, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları*, 2. bası, Ankara, Haziran 2013, sh. 164 vd.

Ancak doktrinde bazı yazarlar, kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olan icrai veya ihmali davranışı ile, belli bir kişinin mağduriyetine veya kamunun zararına sebep olmasının ya da bir kişiye haksız bir menfaat sağlamasının, görevi kötüye kullanma suçunun neticesi olduğu görüşündedirler (GÖKCAN, Hasan Tahsin: *Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, İrtikâp, Rüşvet Suçları ve Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar*, Ankara, 2008, sh. 82 vd.).

¹³⁵⁸ Gerçekleşen somut tehlikenin, suçun bir unsuru olduğu hususundaki görüş için bkz. LENCKNER, Schönke/Schröder(24), § 126, kn. 12; § 130, kn. 10; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 61; DARAGENLİ, Erman’a Armağan, sh. 184.

¹³⁵⁹ ÖZGENÇ, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk, sh. 191. *Hakeri*, TCK’nın “Yabancı devlet aleyhine asker toplama” suçunun tanımlandığı 306. maddesinin iki ilâ dördüncü fıkraları hükümlerinin bu suç bakımından objektif cezalandırılabilme şartlarını oluşturduğunu kabul et-

Objektif cezalandırılabilme şartlarını kovuşturma şartları ile karıştırmamak gerekir. Objektif cezalandırılabilme şartının arandığı durumlarda, esasen haksızlık oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturabilmesi ve dolayısıyla, failin cezalandırılabilmesi için aranan objektif şartın gerçekleşmesi gerekmektedir^{1360,1361,1362}.

mektedir (HAKERİ, Genel Hükümler, 14. bası, sh. 242). Oysa bu fıkralarda söz konusu suçun **neticesi sebebiyle ağırlanmış halleri** düzenlenmiştir.

¹³⁶⁰ Yeni TCK'nın İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, "Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar" başlıklı Sekizinci Bölüm altında yer alan suçlardan dolayı cezalandırma, "**karşılıklılık koşuluna**" bağlanmıştır (m. 343). Kişinin fiili tüm unsurları ile suç teşkil ettiği halde, suç politikası açısından cezalandırılma karşılıklılık koşuluna (mütekabiliyet şartına) bağlanmıştır. Bu şart, ne işlenen fiilin haksızlık içeriğini ne de failin bu suç dolayısıyla kusurluluğunu etkilemektedir. Fiil, haksızlık özelliğinin yanı sıra, suç olma özelliğini de taşıdığı için, kitabımızın ilk üç basısında benimsediğimiz görüşün aksine, bu durumda bir objektif cezalandırılabilme şartından değil, **kovuşturma şartından** söz etmek daha yerinde olacaktır (Aynı yönde görüş için bkz. KUNTER, Kanuni Unsurlar, sh. 246; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, İkinci Bölüm, §5, III. Aksi yönde görüş için bkz. KANGAL, İÜHFM, LXVIII, sh.160; AKBULUT, Genel Hükümler, 5. bası, sh. 233).

¹³⁶¹ Demirbaş, Türk vatandaşının yurt dışında işlediği bir suç nedeniyle Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere hakkında kovuşturma yapılabilmesi için Türkiye'de bulunmasının bir "objektif cezalandırılabilme şartı" olduğu fikrindedir (DEMİRBAŞ, Genel Hükümler [5], sh. 190). Yazarın, bir *kovuşturma şartı* oluşturan bu durumla ilgili fikrine katılmıyoruz. Nitekim bkz. ŞAHİN, Ceza Muhakemesi Hukuku I, sh. 69.

Demirbaş'ın *Kunter*'den (KUNTER, Kanuni Unsurlar, sh. 241 vd.) iktibas ettiği ve benimsediği görüşe göre, bir şartın gerçekleşmesine failin kendisi sebebiyet veriyorsa objektif cezalandırılabilme şartı, failin dışında başka bir kişi veya organ sebebiyet veriyorsa kovuşturma şartı söz konusudur (DEMİRBAŞ, Genel Hükümler [5], sh. 192). Yazarın bu açıklamalarına göre, şikâyet de bir "objektif cezalandırılabilme şartı" niteliği taşımaktadır (DEMİRBAŞ, Genel Hükümler [5], sh. 192). Karşılıklılık koşulunu bir objektif cezalandırılabilme şartı; buna karşılık, Türk vatandaşının yurt dışında işlediği bir suç nedeniyle Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere hakkında kovuşturma yapılabilmesi için Türkiye'de bulunmasını bir "objektif cezalandırılabilme şartı" olarak kabul eden yazarın bu görüşleri arasında çelişki bulunmaktadır.

¹³⁶² Somut olayda işlenen suç bakımından objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmemesi durumunda ne kararı verilmesi gerektiği hususunda doktrinde tartışma mevcuttur. Bazı yazarlar, faile isnat edilen suçla bağlantılı olarak objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmemesi halinde, beraat kararının verilmesi gerektiği görüşündedirler (KUNTER, Ceza Muhakemesi Hukuku, no. 40, 145; DÖNMEZER/ERMAN I, no. 461; DEMİRBAŞ, Genel Hükümler [5], sh. 193; CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide: *Ceza Muhakemesi Hukuku*, 3. bası, İstanbul, 2005, sh. 453). Buna karşılık diğer bazı yazarlar ise, "beraat kararının verilmesi halinde, diğer hukuk dallarının örneğin idare hukukunun yaptırımlarının da uygulanamayacağı" ve bu nedenle, müsnet suçla bağlantılı olarak objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmemesi halinde fail hakkında beraat kararının değil, ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi gerektiği görüşündedirler (ÜZÜLMEZ/AKKAŞ, Erciyes ÜHFD, II(2007), sh. 76).

Somut olayda işlenen suç bakımından objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmemesi durumunda **beraat** kararı verilmesi gerektiği yönündeki kabul, 765 s. mülga TCK'nın yürürlükte bulunduğu 1 Haziran 2005 tarihi öncesinde, objektif cezalandırılabilme şartı gerçekleşmese dahi, işlenen fiilin "suç" vasfını devam ettirdiği yönündeki görüşle (DÖNMEZER/ERMAN I, no. 456) çelişmektedir. Bu anlayışa sadık kalındığı takdirde, objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmediği durumlarda kişinin sadece cezalandırılmasından sarf-nazar edilmesi gerekirdi. Ancak bu dönemin önde gelen ceza hukukçularını *Kunter* ve *Dönme-*

Belirtmemiz gerekir ki, bir suç tanımıyla bağlantılı olarak kanunda hem objektif cezalandırılabilme şartına hem de kovuşturma şartına yer verilebilir.

İşlenen suçtan dolayı cezaya hükmedilebilmesi için, objektif cezalandırılabilme şartını oluşturan hususun somut olayda gerçekleşmesi gereklidir. Ancak, somut olayda failin objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleştiğinin bilincinde olması gerekmemektedir. Başka bir deyişle, suçun maddi unsurlarından farklı olarak, objektif cezalandırılabilme şartlarının somut olayda varlığı kast kapsamında mütalaa edilmemektedir. Bu nedenledir ki, cezalandırılabilme şartlarının objektifliğinden söz edilmektedir.

Objektif cezalandırılabilme şartının arandığı suçlarda, suça teşebbüs mümkündür. Ancak, suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde, objektif cezalandırılabilme şartı gerçekleşmediği sürece, fail hakkında cezaya hükmolunamayacaktır¹³⁶³. Hatta, suçun bütün unsurlarının gerçekleşmesine rağmen, objektif cezalandırılabilme şartı gerçekleşmemişse, fail hakkında cezaya hükmolunmaz^{1364, 1365}.

Objektif cezalandırılabilme şartının arandığı suçlarda, suçun işlenmiş ve dolayısıyla tamamlanmış sayılabilmesi için, objektif cezalandırılabilme şartının **gerçekleşmesi** gerekmektedir. Bu itibarla, objektif cezalandırılabilme şartının arandığı suçlarda **dava zamanaşımı süresi**, maddi unsurların yani sıra, bu **şartın gerçekleştiği andan itibaren işlemeye başlamalıdır**¹³⁶⁶.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki, bir neticenin gerçekleşmesinin suçun unsuru olarak değil, objektif cezalandırılabilme şartı olarak kabul edilmesi, failin gerçekleştirdiği fiillerle bu netice arasında illiyet bağının bulunmamasını gerektirmektedir. Aksine, failin gerçekleştirdiği fiillerle objektif cezalandırılabilme şartı olarak kabul edilen netice arasında illiyet bağı çoğu zaman mevcuttur.

zer/Erman, objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmediği durumlarda, suçun oluştuğunu kabul etmelerine rağmen, fail hakkında *beraat* kararı verilmesi gerektiği yönünde görüş dermeyan etmişlerdi (KUNTER, Ceza Muhakemesi Hukuku, no. 40, 145; DÖNMEZER/ERMAN I, no. 461).

¹³⁶³ Dönmezer/Erman (I, no.459) ve Önder (Genel Hükümler II, sh. 421/422), “cezalandırılabilme şartını ihtiva eden suçlara teşebbüs mümkün değildir” diyerek, bu iki durum arasındaki farkı görmemişlerdir.

¹³⁶⁴ JESCHECK Lb(4), sh. 449; MEZGER/BLEI, sh. 114; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(2), sh. 18.

¹³⁶⁵ Bazı yazarlar, objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmesi halinde, artık suçun teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle failin cezasında indirim yapılamayacağı fikrindedir (ÜZÜLMEZ/AKKAŞ, Erciyes ÜHFD, II (2007), sh. 78). Ancak, bu tespit bazı suçlar bakımından doğru olmakla birlikte, objektif cezalandırılabilme şartının arandığı bütün suçlar bakımından aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

¹³⁶⁶ Doktrinde ileri sürülen diğer bir görüşe göre; objektif cezalandırılabilme şartının arandığı suçlarda, suç, maddi unsurların gerçekleştiği anda tamamlanmış olacaktır. Suçun tamamlanmış sayılabilmesi için, objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmesi gerekmemektedir. Bu itibarla, objektif cezalandırılabilme şartının arandığı suçlarda dava zamanaşımı süresi, bu şartın gerçekleştiği andan itibaren değil, maddi unsurların gerçekleştiği, yani fiilin icrasının tamamlandığı ve neticenin gerçekleştiği andan itibaren işlemeye başlar (DEMİRBAŞ, Genel Hükümler [5], sh. 192).

§24. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları

I. Genel Olarak

Kanunda, işlediği suçtan dolayı kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılabilmesi için, bazı koşulların gerçekleşmesi aranabilir. Kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şart olarak arandığı için, ceza muhakemesi hukukunu yakından ilgilendiren bu koşullara sadece bir suç tanımı kapsamında yer verilmesi dolayısıyla açıklama getirmemiz gerekmektedir.

Soruşturma ve kovuşturma şartlarının objektif nitelikte olmaları yani kast kapsamında mütalaa edilmemeleri, bunları objektif cezalandırılabilme şartlarına yaklaştırırsa da; aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Objektif cezalandırılabilme şartları çoğu zaman suçun işlenmesi anında var olan veya suçun işlenmesi ile birlikte ortaya çıkan olgular oldukları halde; soruşturma ve kovuşturma şartının arandığı suçlarda failin cezalandırılması zorunluluğu suçun işlenmesinden sonra gerçekleştirilmesi gereken bir koşula bağlı tutulmuştur. Objektif cezalandırılabilme şartlarından farklı olarak, soruşturma ve kovuşturma şartının gerçekleşmesi mağdurun, suçtan zarar görenin veya belirli mercilerin iradesine bırakılmıştır. Mağdur, suçtan zarar gören veya merci, bu hak ve yetkisini suçun işlenmesinden sonra kullanabilir.

Soruşturma ve kovuşturma şartlarının, maddi ceza hukukunun mu yoksa muhakeme hukukunun mu kapsamına girdiği konusu tartışılmıştır.

Bir görüş, soruşturma ve kovuşturma şartları gerçekleşmeden failin cezalandırılması imkanı bulunmadığı gerekçesiyle, bunların maddi ceza hukuku bağlamında ele alınması gerektiğini savunur. Bu görüşe göre, soruşturma ve kovuşturma şartlarının en önemlilerine ceza kanunu kapsamında yer verilmiş olması, konunun maddi ceza hukuku ile bağlantısını vurgulamaktadır¹³⁶⁷.

Kanaatimizce, bir konuda ceza kanunu kapsamında düzenleme yapılmış olması, bunun bir maddi ceza hukuku konusu olduğunu göstermez. Bir müessesenin maddi ceza hukuku kapsamında mı yoksa muhakeme hukuku kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiği, bunun hukuki mahiyetinden hareketle belirlenmelidir. Bu belirleme, özellikle zaman bakımından uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların çözümü bağlamında büyük bir önem taşımaktadır. Bu itibarla, soruşturma ve kovuşturma şartlarına ilişkin hükümler, hangi kanunda yer alırsa alsın, **ceza muhakemesi hukuku** içinde mütalaa edilmelidirler ve

¹³⁶⁷ RUDOLPHİ/HORN/SAMSON/SCHREIBER: *Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Band I, Allgemeiner Teil, Frankfurt/Main 1975, § 77, no.6-8. İçel de, müşterek yazarı olduğumuz kitabın kendisi tarafından yazılan kısmında bu görüşü savunmaktadır (İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi, 3. bası, İstanbul 2004, sh. 23).

yürürlüğe girdikleri tarih itibarıyla kişinin lehine veya aleyhine sonuç doğurduğuna bakılmaksızın derhal uygulanmaları gerekmektedir¹³⁶⁸.

Soruşturma ve kovuşturma şartları Ceza Muhakemesi Kanununda, Türk Ceza Kanununda ve diğer çeşitli kanunlarda¹³⁶⁹ yer alabilir. Soruşturma ve kovuşturma şartlarının suçun unsurlarından ve diğer maddi ceza hukuku müesseselerinden ayırımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, burada **sadece TCK kapsamında yer verilenler** üzerinde durulacaktır.

II. Şikâyet

Bir suç dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma, kural olarak, mağdurun veya suçtan zarar görenin iradesine bakılmaksızın, kamu adına re'sen yapılır. Ancak, bazı suçlar dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için, Kanun koyucu *şikâyeti* gerekli görür. Şikâyet koşulunun arandığı suçlara, *şikâyete bağlı suçlar* denir.

Şikâyet, mağdur veya suçtan zarar görenin yetkili mercie başvurarak, suç teşkil eden belirli bir fiil dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması yönündeki ira-

¹³⁶⁸ Ancak belirtelim ki, doktrinde aksine düşünen yazarlar da vardır (HAKERİ, Ceza Hukuku, 5. bası, sh. 55: “*Soruşturma şartları açısından da failin lehine olan kanunun uygulanması yoluna gidilmelidir.*”

Keza, işaret etmek gerekir ki, Yargıtay, bir müessesenin düzenlendiği kanundan hareketle, maddi ceza hukuku veya muhakeme hukuku müessesesi olduğuna karar vermiştir:

“*Her ne kadar 765 sayılı TCK’nın 160/2. maddesinde düzenlenen izin müessesesi şeklen bir usul kuralı olarak görünmekte ise de; tıpkı şikâyet, şikâyetten vazgeçme, zamanaşımı, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı gibi dava şartına ilişkin müesseselerde olduğu üzere, maddi ceza hukuku içinde düzenlenmiş bir müessese olup, maddi ceza hukuku ile sıkı sıkıya bağlı, cezayı doğrudan etkileyici bir nitelik taşımaktadır.*

Bu bakımdan, dava şartı olan izin müessesesinin 765 s. TCK’nın 2, 5237 s. TCK’nın 7. maddesinin öngördüğü lehe yasa uygulaması kapsamına dahil olduğu kuşkusuzdur.” 9. CD, 26.12.2005, E. 2005/7865, K. 2005/9799.

Bu kararda, “izin” müessesesinin, hukuki mahiyeti tartışılırken, konu ile hiç ilgisi olmayan, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı gibi kusur yeteneğine ve dolayısıyla ceza sorumluluğuna etki eden hallerle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutulması doğru olmamıştır. Ayrıca, söz konusu kararda çelişkili açıklamalar da yer almaktadır. Bir “dava şartı” olduğu açıkça belirtilen “izin” müessesesi ile ilgili olarak maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulama kurallarının uygulanabileceği kabul edilmektedir.

¹³⁶⁹ Örneğin, 5411 sayılı **Bankacılık Kanununun** 162. maddesinin ikinci fıkrasına göre;

“*Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir.*”

Buna göre, örneğin banka kaynaklarının zimmete geçirilmesi suretiyle işlenen özel nitelikteki zimmet (mülga 4389 s. Bankalar Kanunu, m. 22, f. 3; 5411 s. Bankacılık Kanunun, m. 160) suçlarından dolayı BDDK ve TMSF tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulması gerekir. Bu başvuru bir **soruşturma ve kovuşturma şartı** niteliğindedir. Bu koşul gerçekleşmeden, Bankacılık Kanununda tanımlanan suçların gerçekleştiğinden bahisle kamu davası açılmaz ve hatta, Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma işlemleri başlatılamaz.

desini açıklamasıdır. Eğer suçun soruşturma ve kovuşturulması şikâyet koşuluna bağlanmışsa, bu koşul gerçekleşmedikçe C. savcısı soruşturma yapamayacaktır.

Suçların şikâyet koşuluna bağlı tutulmalarının değişik nedenleri vardır. Haksızlık içeriği kamu adına re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılmasını gerektirmeyecek kadar az olan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdur veya suçtan zarar görenin şikâyetine bağlı kılınmıştır. Örneğin kasten yaralamanın basit şekli, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığının gündüz ihlali, hakaret, mala zarar verme böyledir. Bu gibi hafif suçlarda ilgililerin şikâyetçi olmaması durumunda Devletin cezalandırmakta ısrar etmesi gereksiz görülmüştür.

Diğer bazı suçlarda ise, suçtan zarar görenin iradesi dışında suçun başkaları tarafından öğrenilmesinin sakıncaları dikkate alınarak şikâyet koşulu öngörülmüştür. Örneğin, eşler arasında cinsel saldırı suçunun işlenmesi halinde (TCK, m. 102, f. 2), C. savcısının kendiliğinden soruşturmaya başlaması mağdurun daha çok zarara uğramasını sonuçlayabilir. Bu tür olayların başkaları tarafından öğrenilip devamlı gündemde kalması suç mağdurunu rahatsız edebilir. Bu nedenle, böyle suçların soruşturma ve kovuşturulması mağdurun isteğine, yani şikâyetine bağlı tutulmuştur¹³⁷⁰.

¹³⁷⁰ Bir suçun temel şekli ile ilgili olarak re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılabilmekte iken, daha az cezayı gerektiren nitelikli hali dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması, şikâyetine bağlı kılınabilmektedir. Örneğin TCK'nın 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla değiştirilen 103. maddesinin birinci fıkrasına göre, çocukların cinsel istismarı suçunun temel şekli ve hatta daha az cezayı gerektiren nitelikli halinden, yani sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar fiilinden dolayı re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılırken; sarkıntılık düzeyinde kalmış istismar fiilinin çocuk tarafından işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyetine bağlı kılınmıştır. Başka bir ifadeyle, sarkıntılık düzeyinde kalmış istismar suçunun çocuk tarafından işlenmesi halinde, bu fail hakkında ancak şikâyet üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış istismar suçu çocuk tarafından müstakilen işlenebileceği gibi, başka kişilerle birlikte iştirak halinde de işlenebilir. TCK'nın 103. maddesinin düzenlemesi karşısında, sarkıntılık düzeyinde kalmış istismar fiilinin çocuk tarafından müstakilen işlenmesi halinde, hakkında ancak şikâyet üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.

Ancak, daha az cezayı gerektiren bu nitelikli hali itibarıyla söz konusu suç,

- a) faili çocuk olmakla birlikte, reşit olan başka kişilerin azmettiren veya yardım eden (şerik) sıfatıyla iştirakiyle,
 - b) çocukla birlikte reşit olan bir kişinin müsterek fail sıfatıyla iştirakiyle,
 - c) faili reşit bir kişi olmakla birlikte, örneğin 17 yaşındaki bir kişinin (çocuğun) azmettiren veya yardım eden (şerik) sıfatıyla iştirakiyle,
- işlenebilir.

Dikkat edilmelidir ki, sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar suçunun failinin sadece çocuk olması halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyetine bağlı kılınmıştır. Bu itibarla, sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar suçu çocukla birlikte reşit olan bir kişi tarafından müsterek fail olarak birlikte işlenmiş ise, re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılmalıdır.

Şikâyet hakkı olanlar, *mağdur* veya *suçtan zarar görendir*. Mağdur veya suçtan zarar gören, çocuk veya akıl hastası ise; kanuni temsilciler de şikâyet hakkını kullanabilirler. Şikâyetin avukat vasıtası ile yapılmasını da kabul etmek gerekir¹³⁷¹.

Şikâyet hakkı, kural olarak miras yoluyla intikal etmez¹³⁷². Ancak, TCK'nın 131. maddesinde hakaret suçuyla bağlantılı olarak bu kurala istisna getirilmiştir

“Mağdur, şikâyet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikâyetle bulunulabilir.” (f. 2)

Mağdur veya suçtan zarar gören birden çok kişi ise hepsinin şikâyet hakkı vardır (m. 73, f. 3). Bu durumda, mağdur veya suçtan zarar görenlerden birinin şikâyeti, soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için yeterlidir. Örneğin, aynı konutu paylaşan kişilere karşı konut dokunulmazlığının ihlali suçu işlenmişse bunlardan birinin şikâyeti ile soruşturmaya başlanabilir. Ancak bir sözle birden fazla kişiye hakaret edildiği hallerde, soruşturma ve kovuşturma sadece şikâyet eden kişiye yapılan hakaretle sınırlı olarak yürütülür. Soruşturma ve kovuşturulması şikâyetle bağlı bir suçun zincirleme (müteselsil) suç olarak işlenmesi halinde, zincirleme suç kapsamında mütalaa edilen her bir suçla ilgili olarak şikâyetin gerçekleşmesi gerekir.

Suçtan zarar görenin tüzel kişi olması halinde, şikâyet hakkı tüzel kişinin yetkili organlarınca kullanılır.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar suçu, faili çocuk olmakla birlikte, reşit olan kişilerin azmettiren veya yardım eden, yani şerik sıfatıyla iştirakiyle işlendiğinde; fail çocuk olduğu için, şeriklerin reşit olmasına rağmen, bütün suç ortakları hakkında ancak şikâyet üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar suçu, faili reşit bir kişi olmakla birlikte, örneğin 17 yaşındaki bir kişinin (çocuğun) azmettiren veya yardım eden (şerik) sıfatıyla iştirakiyle işlendiğinde; fail reşit olduğu için, şerikin çocuk olmasına rağmen, bütün suç ortakları hakkında re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.

TCK'nın 6545 sayılı Kanunla değiştirilen 103. maddesinin birinci fıkrası hükmü, sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar suçunun failinin çocuk olması halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması için şikâyet hakkının kullanılması bakımından da özellik arz etmektedir.

Çocuk tarafından işlenen sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar suçunun mağduru, henüz onbeş yaşını tamamlamamış olan veya tamamlamış olmakla birlikte maruz kaldığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği gelişmemiş olan çocuk olduğu için, şikâyet hakkı bu çocuğun kanuni temsilcisi, yani velisi veya vasisi tarafından kullanılabilir. Ancak, Kanun koyucu, bu durumda suçun mağdurunun da şikâyet hakkını kullanabilmesine imkan tanıyan düzenleme yapmıştır.

¹³⁷¹ “Avukatların şikâyeti konusunda açık bir norm yoktur. Fakat zarar görenin, hakkını koruması için avukata başvurduğunda, ona bu yetkiyi de verdiğini kabul etmemek için sebep yoktur”: 9. CD, 11.11.1986 (İçel/Yenisay, *Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları*, 4. Bası, İstanbul 1993, sh. 305).

¹³⁷² SCHÖNKE/SCHRÖDER, § 61, kn.12.

Şikâyet, mağdur veya suçtan zarar görenin, suç teşkil eden bir fiille ilgili olarak fail-leri hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması talebini içermelidir. Bu itibarla şikâyet, suç oluşturan bir fiile ilişkin olmalıdır ve dolayısıyla, şikâyet failin açıklanması gerekli değildir¹³⁷³. Faillerin kimlikleri gösterilmemiş olsa dahi şikâyet geçerlidir. Suçun birden çok kişi tarafından işlenmesi durumunda, fiille ilgili olarak şikâyet edilmesi yeterli olup, her fail için ayrıca şikâyet bulunulması aranmaz.

Şikâyet fiille ilgili olduğuna göre, mağdur veya suçtan zarar gören tarafından şikâyetin suç ortaklarından bir kısmıyla sınırlandırılması mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, suçun iştirak halinde işlenmesi halinde, şikâyet sadece belirli suç ortaklarıyla sınırlı tutulamaz (*şikâyetin sınırlandırılmazlığı veya bölünmezliği kuralı*)¹³⁷⁴.

Şikâyet suç oluşturan fiile ilişkin olduğu için, mağdur veya suçtan zarar görenin şikâyetinde suç oluşturan fiile ilişkin nitelendirmesinin bir önemi bulunmamaktadır.

¹³⁷³ SCHÖNKE/SCHRÖDER, § 61, kn..25 ve son.

¹³⁷⁴ A ve B ile C arasında bir alacak borç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma çıkar. Bu tartışma sırasında A ve B, C'ye hakaret ederler. C, kendisine hakaret etmesi sebebiyle sadece B hakkında şikâyetle bulunur, A hakkında ise şikâyetle bulunmaz.

Mahkeme, şikâyetin fiile ilişkin olduğu kuralından hareketle, C'nin sadece B hakkında şikâyetle bulunması ve A hakkında şikâyetle bulunmaması karşısında, şikâyetten vazgeçme bağlamında suç ortakları arasında bir ayırım yapılamayacağı, C'nin şikâyetten vazgeçme yönündeki iradesinin sadece B yönünde değil, A yönünden de dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle, hakaret suçundan dolayı C hakkında açılan davada düşme kararı verir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, benzer olaylarda, Esas Mahkemesi tarafından verilen düşme kararlarının, "*hakaret suçunun iştirak halinde işlenmesinin mümkün olmadığı*" gerekçesiyle bozulmasına karar vermiştir (4.CD, **20.5.2014**, E. 2013/3079, K. 2014/17305; 4.CD, **11.2.2014**, E. 2012/38516, K. 2014/4012).

Buna karşılık, Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise, bütün kasıtlı suçlar gibi hakaret suçunun da iştirak halinde işlenebileceğini ve iştirak halinde işlenen hakaret suçu dolayısıyla suçun mağduru suç ortaklarından sadece biri hakkında şikâyetten vazgeçtiği takdirde, şikâyetin ve şikâyetten vazgeçmenin fiile ilişkin olması sebebiyle, diğer suç ortağı hakkında da şikâyetten vazgeçildiğini kabul etmektedir (15.CD, **17.9.2015**, E. 2015/3126, K. 2015/28924).

Bütün bu olaylarda sorun, hakaret suçunun birden fazla suç ortağı tarafından iştirak halinde işlenmesi sorunu olmayıp, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan bir suçu iştirak halinde işleyen suç ortaklarından bir kısmıyla ilgili olarak şikâyetten vazgeçilmesinin hukuki etkisi sorunudur.

Öncelikle belirtilmelidir ki, şikâyet fiile ilişkindir. İştirak halinde işlenen suçlarda şikâyet suç ortaklarından bir kısmına hasredilemez. Böyle bir hasretme olayının vukuu halinde iki yöntem izlenebilir. Birinci yöntem şikâyetin geçersiz addedilmesidir. Bu yöntemde bilahare şikâyet süresinin geçmesi halinde artık şikâyet hakkının kullanılması söz konusu olamaz. İkinci yöntem ise, vaki şikâyeti bütün suç ortakları bakımından geçerli addetmektir. Kanaatimizce bu ikinci yöntemi kabul etmek, hakkaniyet ve nesafet kurallarına daha uygundur.

4. Ceza Dairesi, gerekçesi yanlış olmakla birlikte, bu ikinci yöntemin vardıgı sonucu kabul etmektedir. Buna karşılık, 15. Ceza Dairesi ise, gerekçesi doğru olmakla birlikte, birinci yöntemin vardıgı sonucu kabul etmektedir.

Bu itibarla, örneğin, güveni kötüye kullanma suçu oluşturan fiille ilgili olarak mağdur tarafından hırsızlık olarak nitelendirilerek şikâyetle bulunulması halinde, şikâyet geçerli sayılacaktır. Buna karşılık, aslında hırsızlık suçunu oluşturan fiil dolayısıyla örneğin güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğundan bahisle şikâyetle bulunulması halinde, vaki şikâyet ihbar olarak kabul edilip, hırsızlık suçunu oluşturan fiilden dolayı soruşturmaya devam edilmelidir. Aynı şekilde, mağdurun ihbarda bulunduğu fiil dolayısıyla başlatılan soruşturma sonucunda, fiilin re'sen takip edilebilen bir suç değil de şikâyete bağlı bir suç oluşturduğunun anlaşılması halinde, vaki ihbar şikâyet sayılarak şikâyet koşulunun gerçekleştiği kabul edilmelidir.

Şikâyet, Kanunda bir şekil şartına bağlanmış değildir¹³⁷⁵. Bu itibarla şikâyet, yazılı bir dilekçeyle yapılabileceği gibi, ispat sorununa neden olmamak için, belli bir suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapılması yönündeki sözlü talebin tutanağa geçirilmesi suretiyle de yapılabilir.

Şikâyet dilekçesinde veya şikâyet talebi üzerine düzenlenen tutanakta, şikâyet edenin kimliğinin ve şikâyetin ne zaman yapıldığının belirtilmesi gerekir.

Şikâyet dilekçesinde veya tutanağa geçirilen beyanda belirli bir ifade biçiminin kullanılması gerekmez. “*Şikâyetçiyim*”, “*davacıyım*”, “*cezalandırılmasını istiyorum*” gibi herhangi bir şekilde soruşturma ve kovuşturma talebi ifade edilebilir. Hatta şikâyetçinin “*ihbar ediyorum*” demesi de şikâyet koşulunu gerçekleştirir. Keza, kamu davasına katılma yönündeki talepte bulunulması halinde de, şikâyet koşulunun gerçekleştiğini kabul etmek gerekir¹³⁷⁶.

Şikâyetin yapılması bir süreye bağlanmıştır. Bunun nedeni, bir yandan failin devamlı soruşturma ve kovuşturma tehdidi altında kalmasını önleyerek, diğer yandan ise, soruşturma ve kovuşturma makamlarının tereddüt içinde bulunmalarını engelleyerek, hukuki güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanmasıdır. 765 s. Kanunda olduğu gibi, (m. 108) yeni TCK’da (m. 73, f. 1) da şikâyet için **altı aylık** süre belirlenmiştir.

Bu süre, mağdur veya suçtan zarar görenin “**fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.**” (m. 73, f. 2)¹³⁷⁷. Ancak, şikâyet hakkının kullanılabilmesi için, o suça ilişkin dava zamanaşımı süresinin dolmamış olması gerekir.

Zincirleme (müteselsil) suçlarda şikâyet süresinin ne zaman başlayacağı tartışmalıdır. Alman ve İsviçre hukuklarında şikâyet süresinin zincirleme suçlarda son suçun işlendiği tarihten itibaren başlayacağını savunan yazarlar bulunduğu

¹³⁷⁵ İçel, ortak yazarı olduğumuz kitabın kendisi tarafından yazılan kısmında, şikâyetin şekil şartına bağlı olduğunu ileri sürmektedir (İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(3), sh.29).

¹³⁷⁶ KUNTER, Kanunî Unsurlar, sh.86. Yargıtay da kamu davasına katılmada şikâyet koşulunun gerçekleştiğini kabul etmiştir. 9. CD, 11.11.1986 (İçel/Yenisey, sh. 305). “*Koğuşturma yapılmasının istenmesi de şikâyet sayılır.*”: 4. CD, 16.9.1986 (İçel/Yenisey, sh. 1071).

¹³⁷⁷ Şikâyet süresinin başlangıcıyla ilgili istisnai bir hüküm olarak bkz. TCK, m. 11, f. 2.

gibi¹³⁷⁸, karşı görüşü, yani şikâyet süresinin her fiil yönünden bağımsız olarak tespit edilmesi görüşünü de savunanlar vardır¹³⁷⁹.

Yargıtay ise, çeşitli kararlarında şikâyet süresinin zincirleme (müteselsil) suçlarda son suçun işlendiği günden değil, fakat her bir suçun işlendiği tarihten itibaren işlemesi gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur. Yargıtay'ı bu sonuca götüren gerekçe, şikâyet süresinin bir zamanaşımı süresi olmayıp, hak düşümü süresi niteliğinde bulunduğu ve bu nedenle 765 s. Kanunun 103. maddesindeki (yeni TCK'nın 66. maddesinin altıncı fıkrasındaki) hükmün şikâyet süresi yönünden geçerli olamayacağıdır¹³⁸⁰.

Zincirleme suçlar, her biri bağımsız nitelikteki suçların birleşmesinden meydana gelir; bu nedenle de ancak kanunun gösterdiği durumlarda bir bütün oluştururlar. Kanunun zincirleme suça bağladığı hükümler dışında ise, her suçun bağımsız niteliklerine göre hareket edilmesi zorunluluğu vardır. Durum böyle olunca, zincirleme suçlarda şikâyet süresinin başlangıcını her suç için ayrı ayrı belirlemek gerekir. Yani, şikâyet süresinin başlangıcı bakımından, müteselsilen işlenen her suç ayrı ayrı dikkate almak gerekir¹³⁸¹.

Kesintisiz (mütemadi) suçlar bakımından şikâyet süresinin ne zaman işleyeceği konusunda bir sorun olmadığını düşünmekteyiz. Kesintisiz suçlarda son hareketin yapıldığı tarihte suçun icrası sona ermiş sayılacağı için, şikâyet süresinin de en erken bu tarihten itibaren işleyeceğini kabul etmek gerekir.

Belirtmek gerekir ki, failden haberdar olma sürenin başlangıcı için gerekli ise de, mağdur veya suçtan zarar görenin, şikâyeti sırasında failin kimliğini bildirilmesi zorunlu değildir. Failin kim olduğunu bilmeyen mağdur veya suçtan zarar gören, sadece fiille ilgili olarak şikâyetini yapabilir. Bu durumda şikâyet süresi henüz işlemeye başlamadığından bir sorun yoktur.

İştirak halinde işlenen suçlarda suç ortaklarından birinin bilinmesi şikâyet süresinin başlaması için yeterlidir.

Bir suçtan dolayı birden fazla kişinin mağdur edilmiş veya zarar görmüş olması halinde, bunların her birinin şikâyet hakkı olduğunu yukarıda belirtmiştik. Durum böyle olunca, şikâyet süresinin başlangıcının da her bir mağdur veya suçtan zarar gören bakımından ayrı ayrı belirlenmesi gerekir¹³⁸². Zira, yeni TCK'ya

¹³⁷⁸ Literatür için bkz. İÇEL, Suçların İçtimai, sh.116, dipnot 137.

¹³⁷⁹ SCHÖNKE/SCHRÖDER, § 73, Vorbemerkungen kn. 17.

¹³⁸⁰ “*Türk Ceza Kanununun 108’inci maddesindeki müddet müruruzaman olmayıp sükûtu hak müddeti olmasına ve bu müddet müruruzaman gibi teselsülün bittiği tarihten değil, suçun işlendiği tarihten başlayacağına göre...*”: 1. CD, 21.9.1954. Diğer kararlar için bkz. İÇEL, Suçların İçtimai, sh.117, dipnot 144.

¹³⁸¹ İÇEL, Suçların İçtimai, sh.118-119.

¹³⁸² MAURACH/GÖSSEL/ZİPF II, sh.677.

göre, “Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.” (m. 73, f. 3).

Zamanaşımından farklı olarak, şikâyet süresinin kesilmesi veya durması söz konusu değildir¹³⁸³. Yargıtay kararlarında şikâyet süresiyle ilgili olarak “hak düşürücü süre” teriminin kullanılmasının nedeni budur¹³⁸⁴.

Şikâyetten vazgeçme ile ilgili olarak, davanın ve cezanın düşmesi bölümünde yaptığımız açıklamalara bakılmalıdır.

III. İzin, Talep ve Karar

Ceza kanunları bir suçtan dolayı **soruşturma ve kovuşturma** veya **sadece kovuşturma yapılabilmesini** mağdur veya suçtan zarar gören dışında bazı makamlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken koşullara da bağlı tutabilirler.

Bunlardan ilki, bir suç nedeniyle kovuşturma yapılabilmesinin Adalet Bakanının “**izin**” vermesi koşuluna bağlanmasıdır. Örneğin, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan “dolayı **kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlı**” kılınmıştır (TCK, m. 299, f. 3). “Temel millî yararlar karşı faaliyetinde bulunmak için yarar sağlama” suçu “savaş hâli dışında işlendiği takdirde, bu nedenle **kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır**.” (TCK, m. 305, f. 3. Ayrıca bkz. m. 306, f. 5). Bu suçların niteliklerine bakıldığında, Kanun koyucunun bazen fiilin özelliklerini bazen ise mağdurun sıfatını dikkate almak suretiyle işlenen suçtan dolayı kovuşturma yapıp yapılmamasına karar verme yetkisinin siyasi sorumluluğu taşıyan yürütme erkine bırakmakta yarar gördüğü gözlemlenmektedir.

Dikkat edilmelidir ki, yeni TCK’nın bu düzenlemesinde “izin”, artık bir soruşturma şartı değil, **sadece bir kovuşturma şartıdır**. Yani C. savcısı, gerekli soruşturma işlemlerini yaptıktan sonra, şayet kamu davasının açılmasına yetecek delilleri elde etmişse, şüpheli hakkında kamu davası açabilmek için Adalet Bakanından izin isteyecektir. Başka bir deyişle, soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için “izin” koşulunun gerçekleşmesi gerekmemektedir¹³⁸⁵.

¹³⁸³ KUNTER, Kanunî Unsurlar, sh. 481 vd.

¹³⁸⁴ 765 s. “TCK. ’nun 108. maddesinin yazılışından açıkça anlaşılacağı üzere, yasa koyucu kovuşturulması şahsi şikâyete bağlı suçlarda ilgililerin zamanaşımı gibi uzun bir süre dava tehdidi altında bulundurulmalarını sakıncalı görerek dava hakkının belirli bir süre içinde kullanılmasını öngörmüştür. Sözü edilen süre bu niteliği ile dava hakkının kullanılması için yasanın koyduğu bir zaman sınırlaması, diğer bir deyimle belli bir hakkı kullanmak üzere davacıya tanınan bir mihilden ibaret olup, uygulayıcılar arasında “hak düşürücü süre” (sükutu hak müddeti) olarak tanımlanmaktadır. ... Hak düşürücü sürenin ise işlemeye başladıktan sonra kesilmesi söz konusu olmadığı gibi, başlama tarihi de dava hakkı olan kimsenin fiilden ve failin kim olduğundan haberdar olduğu gündür.”. CGK, 16.1.1978 (İçel/Yenisay, sh. 212-213).

¹³⁸⁵ Ancak belirtelim ki, yeni TCK’nın 301. maddesinde 30.4.2008 tarihli ve 5759 sayılı Kanunla (RG: 8 Mayıs 2008/26870) yapılan değişiklikle, bu maddede tanımlanan “suçtan dolayı **soruşturma**

Adalet Bakanı tarafından verilen iznin geri alınıp alınamayacağı bir sorun oluşturmaktadır. Alman Ceza Kanununda (§77e) izin koşulu hakkında şikâyetle ilgili bazı hükümlerin uygulanabileceği öngörülmüştür. Böylece, Alman Hukukunda, şikâyetle olduğu gibi, iznin de geri alınmasına imkân tanınmıştır.

765 s. (mülga) TCK gibi yeni TCK’da da bu hususta bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen doktrinde bir görüş, Türk hukukunda da verilmiş olan iznin, koşulların bilahare değişmesi halinde, veren makam tarafından geri alınabileceğini savunmaktadır¹³⁸⁶. Kanaatimizce, bilahare şartlarda bir değişiklik meydana gelse bile, **verilmiş olan izin artık geri alınamaz**. Çünkü, kamu hukukunda yetki istisnadır. TCK’da iznin geri alınabilmesiyle ilgili olarak bir hükme yer verilmemesinden çıkarılacak sonuç bu olmalıdır^{1387, 1388}.

turma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlı” kılınmıştır (fıkra 4). Yukarıda örnek olarak gösterilen diğer suçlardan farklı olarak, 301. maddede tanımlanan suç bakımından Adalet Bakanının izni bir **“soruşturma şartı”** oluşturmaktadır. Bu farklı düzenlemeye rağmen, soruşturulması Adalet Bakanının iznine tabi olan bir suç nedeniyle kovuşturma yapılmasının da Adalet Bakanının iznine tabi olduğu söylenebilir. Ancak, maddede söz konusu suçun sadece soruşturulması Adalet Bakanının iznine tabi tutulmuştur. Bir fiil nedeniyle başka bir suç oluşturduğu ve izin alınmasına gerek olmadığı gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatılmış ve sonuçta kamu davası açıldıktan sonra bu fiilin TCK’nın 301. maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu anlaşılmış olabilir. Bu durumda artık soruşturma sona ermiş ve kovuşturma evresine geçilmiş olduğu için, kanaatimizce, artık Adalet Bakanının iznine gerek yoktur. Aksi yöndeki düşünceyi kabul edebilmemiz için, 301. maddenin dördüncü fıkrasının **“Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.”** şeklinde formüle edilmiş olması gerekirdi. Zira, şikâyetle bağlantılı olarak ilgili suç tanımlarında hep soruşturma ve kovuşturma ibareleri birlikte kullanılmıştır. Bu sorunu, söz konusu kanun değişikliğinin yapıldığı süreçte TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet İYİMAYA’ya ve Başkan Yardımcısı Sayın Hakkı KÖYLÜ’ye izah etmemize rağmen, düzenleme istemediğimiz yönde yapılmıştır.

¹³⁸⁶ İçel, ortak yazarı olduğumuz kitabın kendisi tarafından yazılan kısmında bu görüşü savunmaktadır (İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(3), sh. 36).

¹³⁸⁷ Aynı yönde görüş için ayrıca bkz. ŞAHİN, Cumhur: *Ceza Muhakemesi Hukuku I*, 4. bası, Ankara, Eylül 2013, sh. 67.

¹³⁸⁸ 20.5.2016 tarihli ve 6718 sayılı Kanunla Anayasa’ya eklenen geçici madde (Geçici Madde 20) hükmüne göre, belirli bir tarihe kadar işlenmiş olan, başta Cumhurbaşkanı hakaret suçları olmak üzere pek çok suç, yasama dokunulmazlığı kapsamı dışına tutulmaktadır.

Bu düzenleme karşısında, başta anamuhalefet ve muhalefet partileri genel başkanları olmak üzere, milletvekilleri hakkında Cumhurbaşkanı hakaret gibi suçlardan dolayı soruşturma başlatılmıştır.

Ancak, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen “darbe” teşebbüsü sonrası ülkemizde oluşan siyasi atmosferin bir sonucu olarak, Sayın Cumhurbaşkanı bazı siyasi şahsiyetler tarafından kendisine yönelik olarak gerçekleştirilen hakaret fiilleriyle ilgili olarak “bir defaya mahsus af” yetkisini kullandığını beyan etmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanının bu yöndeki açıklaması teknik anlamda bir af yetkisi kullanımı olarak değerlendirilemez. Cumhurbaşkanı hakaret suçundan dolayı şikâyetten vazgeçme mekanizması da işletilemez. Keza, söz konusu suç dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı olmakla birlikte, Bakanın

Hukukumuzda izin bir süreye bağlı bulunmamaktadır.

İzin, ancak, kanunla yetkili kılınan makam tarafından verilebilir. Bu itibarla, örneğin Adalet Bakanlığına tanınan izin yetkisi, Bakan yerine Bakanlık Müsteşarı tarafından kullanılamaz¹³⁸⁹.

Şikâyetten farklı olarak, izin, soruşturma makamının talebi üzerine gerçekleşir. Yani şikâyete bağlı suçlarda C. savcısı hak sahibinden hakkını kullanıp kullanmayacağını sormazken, izne bağlı suçlarda yetkili makamdan izin isteğinde bulunur¹³⁹⁰.

İzin koşulu suçla ilgili olduğundan, bir suçla ilgili olarak verilen izin, bütün suç ortakları hakkında kovuşturma yapılmasına imkân verir. Buna karşılık, zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği hallerde, bu kapsamda mütalaa edilen her bir suç için izin koşulunun ayrıca gerçekleşmesi gerekir.

Ceza Kanunumuz bazı hallerde işlenen suç dolayısıyla yargılama yapılabilmesini “**talep**” şartına bağlamıştır. Örneğin, yurt dışında işlenen bir suç dolayısıyla bazı hallerde Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için **Adalet Bakanının talepte bulunması** şarttır (TCK, m. 12, f. 1, 3, 4: m. 13, f. 2, 3).

Talebin bir soruşturma ve kovuşturma şartı mı yoksa sadece kovuşturma şartı mı olduğu hususu, bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni TCK’da Adalet Bakanının talebi, belli bir suçla ilgili olarak **yargılama** yapılabilmesi bakımından şart olarak aranmaktadır. Kanaatimizce yargılama, kovuşturma evresinde yürütülen bir faaliyettir. Bu itibarla, yeni TCK’nın düzenlemesinde, “izin” gibi, “talep” de bir soruşturma şartı değil, **sadece bir kovuşturma şartıdır**.

Bu bakımdan, “talep” ile “izin” arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır. Her iki koşulun gerçekleştirilmesinde esas itibarıyla Adalet Bakanlığına yetki verilmiştir. “Talep” ve “izin”, süre koşuluna tabi tutulmamıştır. Keza, “izin” gibi “talep” koşulunun gerçekleşmesi halinde, C. savcısı kamu davasını açmakla yükümlüdür. “İzin” gibi “talep” de bilahare geri alınamaz¹³⁹¹.

verdiği izne dayalı olarak bu suç sebebiyle soruşturma ve kovuşturma başladıktan sonra, artık bu izin geri alınamaz.

Sayın Cumhurbaşkanının belirtilen içerikteki açıklamasına rağmen, mer’î kanuni düzenlemeler karşısında başlatılan bu soruşturmaları sonlandırmaya hukuken imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu hale özgü olarak bir kanuni düzenleme yapılması zarureti ortaya çıkmıştır.

¹³⁸⁹ İçel, ortak yazarı olduğumuz kitabın kendisi tarafından yazılan kısmında izin yetkisinin Adalet Bakanlığı Müsteşarı tarafından da kullanılabileceğini savunmaktadır (İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç Teorisi(3), sh. 36). Yargıtay da bu görüştedir: “Maddedeki - Bakanlık - tabirinin kül halinde düşünülmesi gerekir. Bu yetki, sadece bakanın şahsına verilmiş bir yetki değildir. Bakanlığı temsil eden - müsteşar-’ın vereceği izin de bu nedenle geçerlidir”: 9.CD, 9.3.1978 (İçel/Yenisey, sh. 752).

¹³⁹⁰ MAURACH/GÖSSEL/ZİPF II, sh.679; ÖNDER, Genel Hükümler II, sh. 417.

¹³⁹¹ ŞAHİN, Ceza Muhakemesi Hukuku I, sh. 65.

765 s. (mülga) TCK'nın sisteminde ayrıca “*müracaat*” koşulunun arandığı suçlar mevcuttu (m. 164, 165). Yeni TCK'nda ise, müracaat yerine şikâyet kavramı kullanılmıştır. Bu itibarla, yabancı devlet başkanına karşı işlenen suç, Türk hukukuna göre soruşturulması ve kovuşturulması şikâyetle bağlı bir suç ise; bu suçtan dolayı “*soruşturma ve kovuşturma (yapılması) yabancı devletin şikâyetine bağlıdır.*” (m. 340). Keza, yabancı devlet bayrağına karşı hakaret suçundan “*dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikâyetine bağlıdır.*” (m. 341).

Diğer bir soruşturma ve kovuşturma koşulu, “**karar**”dır. Yeni TCK'nın 67. (765 s. Kanunun 107.) maddesinde zamanaşımını durduran bir neden olarak öngörülen *karar* koşulunun başlıca örneği Anayasanın 83. maddesinde düzenlenen **yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı**dır. Diğer deyişle, milletvekili hakkındaki kovuşturma yasağının TBMM tarafından kaldırılmasına ilişkin karar, bir **soruşturma ve kovuşturma koşulu** olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasağın TBMM tarafından kaldırılabilmesi için, C. başsavcılığı tarafından talepte bulunulması gerekir. Bu istem, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık aracılığı ile TBMM Başkanlığına sunulur. TBMM bünyesindeki ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra Genel Kurul tarafından milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı verildiği takdirde, Anayasanın 83. maddesinde öngörülen yasak soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapılabilir.

Üçüncü Bölüm YAPTIRIM TEORİSİ

§25. Ceza Hukuku Yaptırımlarının Türleri, Amaçları ve Nitelikleri

I. Yaptırım Türü Olarak Ceza ve Güvenlik Tedbiri

Kişi, hukukun kendisine yüklediği yükümlülüklerle aykırı davranışta bulunması halinde, *sorumlu* tutulur.

Yükümlülüklerle aykırı olarak ve bu nedenle haksızlık oluşturan bir davranış gerçekleştirildikten sonra, bu haksızlığı artık gerçekleştirmemiş hale döndürmek mümkün değildir. Ancak, yükümlülüklerle aykırılık dolayısıyla gerçekleşen haksızlık karşısında, hukuk düzeninin idamesi amacıyla, bazı *yaptırımlar* uygulanmaktadır. Bu itibarla, yaptırım, insanın yükümlülüklerine aykırı davranışının gerekli kıldığı hukuki sonuçtur. Gerçekleşen haksızlık dolayısıyla, hukuk düzeninin kişiler arasında oluşturduğu denge bozulmuştur. Yaptırım tatbikiyle güdülen genel amaç, bu dengenin yeniden tesis edilmesidir¹.

Kişi yükümlülüklerine uygun davranma doğrultusunda bir mecburiyet ile karşı karşıya değilse de; bir başkasının sahip olduğu değerleri, bir başkasının hukukunu korumaya yönelik yükümlülüklerle aykırı davranışta bulunması halinde, hakkında bu aykırı davranışın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaya veya en azından azaltmaya yönelik yaptırım uygulanması *zorunluluk* arz etmektedir. Bu itibarla, yaptırım uygulanmasıyla güdülen amaçlardan birisi, bir *haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyetini gidermektir*.

Yaptırım uygulanmasıyla güdülen bir başka amaç ise, *haksızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde belli fiili ve hukuki sonuçlar doğurması, bu kişiye belli etkilerde bulunmasıdır*. Ceza hukuku yaptırımlarının asıl amacı budur.² Bu amaca hizmet eden iki

¹ Her bir somut olaya ilişkin olarak müeyyide tatbiki suretiyle toplumu oluşturan fertler nezdinde *şerr* (=Böse, kötülük) karşısında *hayrın* (=Gute, iyilik), *haksızlık* (=Unrecht, Zulm) karşısında *hakkın* (=Recht) mutlak üstünlüğü, mutlak muteberiyeti bir defa daha pekiştirilmektedir (PAPA XII. PIUS'un 3 Ekim 1952 tarihinde Roma'da tertiplenen VI. Milletlerarası Ceza Hukuku Kongresinde yaptığı konuşma, in: JZ 1953, sh. 771 vd.)

² “Ceza hukukunda, cezanın infaz edilmesiyle güdülen amaç kişiye gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla etkili bir uyarıda bulunmak ve etkin pişmanlık duymasını sağlamaktır. Mahkemelerde hükmolunan cezanın infazıyla hükümlünün gelecekte sosyal sorumluluğa sahip olarak suçsuz bir hayat sürmeye yatkın duruma getirilmesi gerekmektedir. Çağdaş ceza hukukunda ceza yaptırımlarının belirlenmesindeki temel amaç ise suçlunun ıslahı, yeniden suç işlemesinin ve toplum için sürekli bir tehlike olmasının önüne geçme ve dolayısıyla topluma tekrar yararlı bir birey hâline getirilmesini sağlamaktır. Bu nedenle günümüzde suçlar için ceza yanında ya da yerine bir kısım tedbirlerin uygulanması söz konusu olmaktadır. Yine sanık hakkında hükmolunacak olan hapis cezasının ertelenebilmesi ile suçlunun, toplum içinde özgürlüğü kısıtlanmadan ceza infaz kurumlarının olumsuz etkilerinden de kurtarılarak toplumla sosyal bağla-

yaptırım türü mevcuttur: **Ceza ve güvenlik tedbiri**. Bu yaptırım kategorisinde mütalaa edilen *cezalandırmakla güdülen amaç*, kitabımızın Giriş bölümünde açıklandığı üzere, suç teşkil eden bir haksızlığı gerçekleştiren kişinin, bu suçu işlemek dolayısıyla içinde bulunduğu kusurluluk durumundan ibra olmasını sağlamaktır^{3,4}.

Bazı durumlarda ise, hukuka aykırı davranışın gerçekleştirilmesi dolayısıyla, yaptırım olarak *güvenlik tedbiri* uygulanmaktadır. Bu bakımdan, güvenlik tedbiri, gerek haksızlığı gerçekleştiren kişinin kendisini gerek toplumu belli zarar tehlikelerinden korumak amacına yönelik bir yaptırımdır. Güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için gerçekleşen haksızlık dolayısıyla kişinin kusurlu telâkki edilmesi gerekli değildir⁵.

II. Kusur ve Ceza ilişkisi: nulla poena sine culpa

Kişinin işlediği suçtan dolayı kusurlu olması, cezanın meşruluk zeminini oluşturmaktadır^{6,7}. Ceza; kişi işlediği suçtan dolayı kusurlu bulunduğu için; bir başka ifadeyle, hukuki anlam ve sonuçlarının bilincinde olarak, haksızlık teşkil eden fiili işleme hususunda bir tercihte bulunduğu için; kişiye tatbik edilir. Bu itibarla kusurluluk, haksızlık teşkil eden bir fiili işleyen kişi hakkında bu fiil dolayısıyla bulunulan bir muaheze (kınama) yargısıdır⁸.

Kusurluluk, muahezenin (kınamanın) somutlaşmış bir ifadesi olan cezanın⁹ temelini teşkil etmektedir. Bu nedenle, cezanın tatbiki, kişiyi soyut araç durumuna irca etmemelidir. İşlediği fiil bir haksızlık teşkil etmemesine rağmen, kişinin herhangi bir şekilde cezalandırılması gibi; gerçekleştirdiği haksızlık daha hafif bir ceza ile mukabele edilmeyi gerekli kılmasına rağmen, kişinin hak etmeyeceği ağırlıkta bir ceza ile cezalandırılması, bu kişiyi soyut bir konu (obje) durumuna irca edecektir. İşlediği fiil dolayısıyla muahezeye layık görüldüğü için,

rı koparılmadan ve her şeyden de önemlisi hayatın normal akışı değişmeden ıslah edilmesi amaçlanmaktadır. Cezaların kişiselleştirilmesine yönelik bu düzenlemeler, kamu yararının da bir gereğidir.” (Anayasa Mahkemesi, 20.7.2022, E. 2022/53, K. 2022/91, pn. 15. Ayrıca bkz. Anayasa Mahkemesi, 5.7.2012, E. 2012/9, K. 2012/103; pn.).

³ Ancak, *Önder*, cezanın uygulanmasına duyulan gerekliliği; Devletin korunmasına, Devletin varlığını idame ettirmesine duyulan ihtiyaçla izah etmeye çalışmaktadır (ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 8, 14).

⁴ Türk doktrinde bazı yazarlar, klasik suç teorisinin etkisinde kalarak, **ceza**yı suç işleyen kişiye karşı icra edilen bir **kötülük** olarak tanımlamaktadırlar (CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş(4) sh. 4). Buna karşılık, ceza hukukunun bugün ulaştığı bulunduğu gelişmişlik düzeyinde ceza bir kötülük olarak telakki edilmemektedir (ÜNVER, Hukuksal Değer, sh. 463).

⁵ Aynı mealde ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 20/21, 101.

⁶ Arth. KAUFMANN, Das Schuldprinzip, sh. 15 vd.; JAKOBS, Das Schuldprinzip, sh. 7.

⁷ Bütün bu açıklamalarımızla ilgili olarak bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Suçun Yapısında Kusur*, İstanbul, 1997 (yayınlanmamış Doçentlik Tezi), sh. 125 vd.

⁸ BAUMANN/WEBER/MITSCH, § 18, kn. 23; RUDOLPHI, Systematischer Kommentar, Vor. § 1, kn. 82, Vor. § 19, kn. 1. Kusur, davranış normlarına aykırı davranışın bir kişiye isnadiyetini ifade etmektedir (RUDOLPHI, Grundfragen, sh. 73).

⁹ Arm. KAUFMANN, Normentheorie, sh. 228.

kişi cezalandırılmalıdır. Bu itibarla, gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla kişi cezalandırılırken, şahsiyetine duyulan hürmet, saygınlık ihlâl edilmemelidir. Ceza tayininde ve tatbikinde riayet edilmesi gereken bu sınır, aynı zamanda cezalandırmak ile güdülen kamusal faydanın da sınırını oluşturmaktadır.

Ceza, değerden soyut bir tepki değildir. Aksine, işlediği fiil dolayısıyla failin sosyaletik değerler ölçüsünde azarlanmasını ifade etmektedir¹⁰. Bu itibarla, kusurluluk, cezalandırılabilirlik bakımından büyük bir önemi haizdir.

“Genel veya özel önleme mülahazası”yla da olsa; işlediği fiil dolayısıyla kusurlu bulunmayan bir kimsenin cezalandırılmasının hiçbir haklı yönü olamaz¹¹. Bu nedenle, kusurluluk, işlediği fiil (gerçekleştirdiği haksızlık) dolayısıyla kişinin cezalandırılabilmesinin yegane dayanağını oluşturmaktadır^{12, 13}.

Önleme mülahazası, kusurun dayanağı olmaktan ziyade; işlediği fiil dolayısıyla kusurlu telâkki edilen kişi hakkında genel ve özel önleme mülahazasıyla ceza olarak bir müeyyide tatbiki cihetine gidilmektedir. Bu itibarla, kusurluluk, genel ve özel önleme amacına matuf müeyyidenin dayanağını oluşturmaktadır. Kusur kavramı ne genel önleme mülahazasından hareketle izah edilebilir, ne de bu kavram yerine genel önleme mülahazası ikame edilebilir¹⁴.

Cezalandırma ile güdülen birincil amaç, suç teşkil eden bir haksızlığı gerçekleştiren kişinin, bu suçu işlemek dolayısıyla içinde bulunduğu kusurluluk durumundan ibra olmasını sağlamaktır. Hukuk toplumundaki sosyal düzenin idamesi, cezalandırmak ile güdülen amacın bir tezahürü olarak anlaşılmalıdır¹⁵. Ceza-

¹⁰ LENCKNER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. §§ 13 ff., kn. 103.

¹¹ ROXIN, Kriminalpolitik, sh. 33; LENCKNER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. §§ 13 ff., kn. 103.

¹² SCHUMANN, Grundfragen, sh. 174.

¹³ “Motorlu taşıtının egzoz emisyon ölçümünü yaptıran ve bu konuda Kanunla kendisine verilen görevi yerine getiren kişi, taşıtının egzoz emisyonunun standart değerlerin altında olduğu, idare ya da idare tarafından yetkili kılınan ölçüm istasyonlarınınca tespit edilmiş kişi konumundadır. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getiren motorlu taşıt sahibi, teknik cihazlarla yapılabilen ölçümün doğru yapıp yapılmadığını kişisel olarak kontrol etme olanağına sahip olmadığı gibi mevzuat uyarınca yeniden ölçüm yaptırması gereken tarihten önce ölçüm yaptırma yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Oysa idari yaptırımlar bakımından da geçerli olan Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan ve kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesini barındıran “cezaların şahsiliği ilkesi” gereğince kişilerin cezalandırılabilmesi için kusurlu bir davranışının bulunması gerekir. Bu anlamda, bir kişinin ihmali davranışı nedeniyle kusurlu sayılması ve cezalandırılabilmesi, o konuda icraî bir davranışta bulunma yükümlülüğünün varlığına ve bu yükümlülüğü yerine getirmemesine bağlıdır.” (Anayasa Mahkemesi, 22.4.2015, E. 2015/35, K. 2015/40. Kusurluluk ve ceza sorumluluğu bağlamında değerlendirmeler için ayrıca bkz. Anayasa Mahkemesi, 4.3.2021, E.2019/47, K.2021/16; Anayasa Mahkemesi, 14.3.2019, E.2019/1, K.2019/14).

¹⁴ STRATENWERTH, Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips, sh. 36 vd.; SCHUMANN, Grundfragen, sh. 67.

¹⁵ Buna karşılık Jakobs, hukuk toplumundaki sosyal düzenin idamesinin teminini, cezalandırmakla güdülen yegane amaç olduğu fikrindedir (JAKOBS, Das Schuldprinzip, sh. 7). Keza Önder, cezanın uygulanmasına duyulan gerekliliği; Devletin korunmasına, Devletin varlığını

nın asıl özelliği, *kefare*t teşkil etmesidir. Bir başka ifadeyle, kişinin işlediği suçtan dolayı kusurunun örtülmesidir; kısacası, kişinin resosyalize edilmesidir. Böylece, belli bir cezaya mahkûm olan kişi, bu cezanın infazıyla, önce, işlediği suçtan dolayı sorumluluğun kendi uhdesinde olduğunun şuuruna, bilincine kavuşmalıdır. Cezanın infazıyla kişi, gerçekleştirdiği haksızlıktan dolayı sorumluluk altında olduğunu aktüel bir şekilde hissedecek ve böylece, kusurundan ibra olacaktır¹⁶. Ezcümle; cezanın birincil amacı -kural olarak- *müsbet anlamda özel önlemedir*; suç işleyen kişinin yeniden topluma kazandırılmasıdır; toplum bakımından zararsız ve güvenilir bir kişi haline getirilmesidir¹⁷.

Kusur prensibine riayet edilmeksizin tatbik edilen cezanın hiçbir meşruluk temeli mevcut değildir. Kusur prensibi, aynı zamanda tatbik edilecek ceza bakımından bir sınırlama da ifade etmektedir¹⁸; bir başka ifadeyle; kusur prensibi, tatbik edilecek cezanın amaca uygunluğunu da temin etmektedir. Kusur prensibine riayet etmeksizin, “kamusal yarar gereği” tatbik edilen ceza, kişiyi nesne durumuna irca edecektir. Keza, kusur prensibinin gerektirdiğinden daha hafif bir cezanın tatbiki, cezalandırma ile güdülen amaçla bağdaşmaz, bu amacın gerçekleşmesine imkân sağlamaz¹⁹.

Kusura ilişkin yapılan tetkik sonucunda, kişinin işlediği haksızlık açısından hem algılama hem de irade kabiliyetinin mevcut olduğu yargısına varılabilir. Başka bir

idame ettirmesine duyulan ihtiyaçla izah etmeye çalışmaktadır (ÖNDER, Ayhan: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, cilt III, 1989, sh. 8, 14).

¹⁶ BOCKELMANN, Paul: *Vom Sinn der Strafe*, in: Heidelberger Jahrbücher V, sh. 25; aynı yazar: *Schuld und Sühne*, 1957 (30 sahifeden ibaret bütün eser); SCHMIDHAEUSER, Eberhard: *Vom Sinn der Strafe*, 2. Auflage, 1971, sh. 43 vd.; WALDER, Hans: *Die Vernehmung des Beschuldigten*, Hamburg, 1965, sh. 18; RÖSSNER, Dieter: *Autonomie und Zwang im System der Strafrechtsfolgen*, in: Festschrift für Jürgen Baumann, 1992, sh. 269 vd.

¹⁷ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Kitabımızın Giriş Bölümündeki açıklamalar ve ayrıca, ÖZGENÇ, İzzet: *İnsan Öldürme İle İlgili Kur'an Hükümlerinin Günümüz Ceza Hukuku Düşüncesine Aktarılması*, in: Dr.Dr.h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan, Editörler: F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoğlu, A. Sözüer, F. Turhan, Ankara, Mayıs 2018, sh. 503 vd.

¹⁸ Kusur, hem cezanın sebebi, hem de sınırının tayininde bir ölçüdür (SCHMIDHAEUSER, Lehrbuch, § 7, kn. 7; RUDOLPHI, Systematischer Kommentar, vor § 19, kn. 1; aynı yazar, Grundfragen, sh. 75; LENCKNER, Schönke/Schröder(23) Vorbem. §§ 13 ff., kn. 103, 112; ACHENBACH, Schuldlehre, sh. 4, 10; MERAKLI, Ceza Hukukunda Kusur, sh. 53 vd.

¹⁹ *Schünemann*'a göre, işlediği fiil dolayısıyla kusurlu addedilen faile ceza verilebilmesi için münhasıran önleme amacı dikkate alınmalıdır. Yani, faile ceza verilebilmesi için, işlediği fiilden dolayı mutlaka kusurlu telâkki edilmesi gerekir. Ancak, bu yeterli değildir. Ayrıca önleme amacı, işlediği somut fiilden dolayı failin cezalandırılmasını gerekli kılmalıdır (SCHÜNEMANN, Grundfragen, sh. 187 vd; aynı yazar, Schmitt-F., 133/134). Bu anlayışa göre; ceza, münhasıran önleme amacına hizmet etmektedir ve bu nedenle, mahiyet ve miktarı münhasıran önleme mülahazasıyla belirlenmelidir (SCHÜNEMANN, Grundfragen, sh. 188 vd.). Cezanın miktarının tayininde; ilk önce, somut olayda faili suç teşkil eden fiili işlemeye sevkeden faktörler, hukuki değer in ihlâl ölçüsü ve dolayısıyla, haksızlığın ağırlığı; ikinci sırada ise, faildeki suç işleme enerjisinin yoğunluğu dikkate alınmalıdır (SCHÜNEMANN, Grundfragen, sh. 190 vd.). Netice olarak, klasik anlayıştaki “kusur nisbetinde ceza” ifadesi, yanıltıcı bir ifade olarak nitelendirilmektedir (SCHÜNEMANN, Grundfragen, sh. 190, 194 vd.).

ifadeyle, kişi işlediği fiilin bir haksızlık oluşturduğunun bilincinde ise ve ayrıca, bu fiil bağlamında davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğine sahip ise, kusurlu addedilecektir. İşlediği suç dolayısıyla kusurlu telâkki edilen kişinin, kural olarak, cezalandırılması cihetine gidilecektir²⁰. Çünkü **ceza, işlemiş olduğu haksızlıktan dolayı bir insanın muaheze edilmesi gerektiği hususun-daki yargının somutlaşmasıdır, maddi bir muhteva kazanmasıdır**²¹.

Gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla kişide kusurun iki unsurundan (**algılama ve davranışlarını yönlendirme [irade] yeteneğinden**) birinin veya her ikisinin birden mevcut olmaması halinde, kişinin kusurundan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Yani, kişide kusurun her iki unsurundan, algılama veya irade kabiliyetinden sadece bir tanesinin ya da her ikisinin birden mevcut olmadığı durumlarda hakkında kusur yargısında bulunulamayacaktır. Ancak, bu durumda dahi kişinin gerçekleştirdiği fiil, haksızlık özelliğini muhafaza etmektedir. Bu itibarla, işlediği haksızlıktan dolayı kusurlu telâkki edilmediği durumlarda kişinin cezaî sorumluluğu cihetine gidilemeyecektir. Çünkü, ceza hukukunun temel prensiplerinden bir tanesi, **kusursuz ceza olmaz (nulla poena sine culpa)** prensibidir²². “Kusur ilkesi” olarak nitelendirilen bu evrensel hukuk kuralı, gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla kusurlu addedilmemesi halinde kişi hakkında sadece cezaya hükmlenemeyeceğini ifade etmektedir²³. İşlediği fiil, haksızlık ve dolayısıyla, suç teşkil etme özelliğini devam ettirdiği için; bu durumda, her ne kadar kişi hakkında cezaya hükmedilemeyecek ise de, şayet bir tehlikelilik hali söz konusuysa, koruma ve ıslah amaçlı olarak **güvenlik tedbiri** uygulanabilecektir^{24, 25}. Bu itibarla, işlediği fiil dolayısıyla kusurlu telâkki edilmeyen kişi

²⁰ Ancak, işlediği fiilden dolayı kusurlu telâkki edilmesine rağmen, somut olayda mevcut olan şahsi cezasızlık sebebi, cezayı bertaraf eden şahsi hal gibi bir nedenle, failin cezalandırılması cihetine gidilmeyebilir.

²¹ Arm. KAUFMANN, Normentheorie, sh. 228, 229.

²² Öztürk, sözkonusu prensibi “kusursuz suç ve ceza olmaz” şeklinde telâkki etmektedir (ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 22 vd., sh. 311 vd). Haksızlık ve kusur arasındaki ayrımı bertaraf eden bu anlayış, doğru değildir.

²³ İÇEL, Kayıhan/DONAY, Süheyl: Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım I, 1987, sh. 76/77.

²⁴ MAURACH/ZIPF I, sh.484/485.

²⁵ Ancak, Öztürk, suç teşkil eden fiiller ve “suça benzeyen ve fakat teknik anlamda suç olarak nitelenebilen emniyet tedbirlerini gerektiren fiiller” olmak üzere bir ayırım yapmaktadır. Öztürk’e göre, “esas yaptırımı emniyet tedbiri olan fiillerin günümüz suç genel teorisi çerçevesinde suç olarak nitelenebilmesi mümkün değildir”. Çünkü, “Ceza normunu anlayamayan, anlayabildiği halde ona uygun hareket edemeyen bir kimsenin hareketi teknik anlamda suç olarak nitelenebilir” (ÖZTÜRK, Bahri: Ceza Muhakemesi Hukukunda Koğuşturma Mecburiyeti [Hazırlık Soruşturması], 1991, sh. 3). Çünkü, Öztürk’e göre, suç, ancak “kusur yeteneği (isnad kabiliyeti) bulunan bir kimsenin tipe (kanunî unsura) uygun, Hukuka aykırı, kusurlu hareketidir” (ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 2, 200 vd.); “isnat kabiliyeti bulunmayan kimselerin fiilleri «suç» olarak nitelenebilir” (ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 201, 313 vd.); “kusursuz kimse bakımından cezalandırılacak suç yoktur” (ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 22, 316); “kusur yoksa, suç da yoktur” (ÖZ-

hakkında verilmesi gereken karar, beraat kararı değildir²⁶. Beraat kararı, ancak bir haksızlığın söz konusu olmadığı durumlara, yani olayda en azından bir hukuka uygunluk sebebinin mevcut olduğu hallere münhasır kılınmalıdır. Çünkü, bu hallerde kişi haklıdır ve kendisine hiçbir hukuki müeyyide tatbik edilemez. Beraat (“berâet”), bir haksızlık iddiasından temiz, ilişiksiz çıkmayı, aklı, arılığı, aklanmayı ifade etmektedir^{27, 28}.

TÜRK, Ceza Hukuku, sh. 22, 316). Öztürk, ayrıca, “failin değil, fiilin kusurlu olması”ndan bahsetmektedir (ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 23). Bu görüşler, doğru değildirler:

Kusur, haksızlık teşkil eden bir fiil işlemesi dolayısıyla kişi hakkındaki bir muaheze yargısı olması itibarıyla; bir fiil, kusursuz bir şekilde işlense dahi, haksızlık ve dolayısıyla, suç vasfını muhafaza edecektir. Demek ki, failin kusurlu veya kusursuz telâkki edilmesi, işlenen fiilin suç vasfını haiz bir haksızlık olması üzerinde etki doğurmayacaktır. Başka bir ifadeyle, bir haksızlık, failin kusurlu telâkki edilip edilmeyeceğine bakılmaksızın, suç vasfını haizdir. Bu itibarla, meselâ işlediği fiilin hukuki anlam muhtevasını idrak edemeyecek derecede akli bozuklukla malûl bir akıl hastasının bir insanı öldürmesi halinde, işlenen fiil suç teşkil etmektedir; ancak, failin idrak kabiliyetinden ve dolayısıyla, kusurundan bahsetmek mümkün olmayacaktır. İşlediği haksızlık dolayısıyla failin kusursuz bulunması halinde, sadece uygulanacak müeyyide farklılık arzedecektir. Şöyle ki, suç teşkil eden muayyen bir haksızlık işlemesinden dolayı failin kusurlu bulunması halinde tatbik edilecek müeyyide, kural olarak, bir cezadır. Buna karşılık, failin idrak ve/veya irade kabiliyetinin bulunmaması ve dolayısıyla, kusursuz telâkki edilmesi halinde dahi işlenen fiil, haksızlık, suç vasfını muhafaza edecektir. Ancak, kişi kusursuz telâkki edildiği için, kendisine ceza tatbiki mümkün değildir. Sadece failin tehlikelilik arzemesi durumunda koruma ve ıslah tedbirlerine hükmedilmesi cihetine gidilecektir.

Haksızlık ve kusur arasındaki ayrımı bertaraf eden bu anlayış, bizi zorunlu olarak ancak kusur ehliyetine, yani idrak ve irade kabiliyetine sahip kişilerin normun muhatabı olabileceği sonucuna götürür. Bu anlayış ise, “emirler teorisi”nin (Imperativentheorie) bir benzeri mahiyet arz etmektedir. Ancak, bu görüşlerine rağmen Öztürk, kusur ehliyeti olmayan kişilerin işledikleri fiillerin haksızlık teşkil ettiğini, yani “Hukuka aykırı olmaya devam ettikleri”ni, doğru olarak, vurgulamaktadır (ÖZTÜRK, Ceza ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 185/186, 267). Şayet bu mantıkla hareket edecek olursak; Hukuka aykırı bir fiile suç vasfını kazandıran unsurlardan bir tanesi de “isnad kabiliyeti” ve dolayısıyla, kusurluluk olacaktır. Unutulmamalıdır ki; suç olarak tavsif edilsin edilmesin, haksızlığın sözkonusu olduğu her fiil açısından bu fiil failinin kusurlu olup olmadığının ayrıca tetkik edilmesi gerekir. Bu itibarla, şayet işlenen fiil, haksızlık teşkil ediyorsa, suç vasfını da muhafaza ediyor demektir. Bunun suç teorisi açısından doğurduğu önemli sonuçlar vardır: Meselâ kişi bir akıl hastasının tecavüzüne karşı meşru müdafaada bulunabilir. Ayrıca, iştirakte sınırlı bağlılık prensibi gereğince; meselâ kusur ehliyeti olmayan akıl hastasının veya yaş küçüğünün işlediği suça azmettiren veya yardımda bulunan olarak iştirak etmek mümkündür. Meğer ki, bu akıl hastası veya yaş küçüğü üzerinde bir hakimiyet kurulsun. Azmettiren veya yardımda bulunan olarak iştirak edilen esas fiil faili her ne kadar kusursuz telâkki edilmekteyse de; gerçekleştirdiği haksızlığın ilişkin olduğu suç tipi, özellikle azmettiren ve yardımda bulunan açısından *ikaz, uyarı fonksiyonunu* (Appelfunktion) icra etmektedir.

²⁶ ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 130/131.

²⁷ Alman Hukukunda, kusursuzluk halinde dahi “Freispruch” kararı verilmektedir (ROXIN, Claus: *Strafverfahrensrecht*, 20. Auflage, 1987, sh. 303). Ancak, belirtmek gerekir ki, anlam muhtevası itibarıyla, “Freispruch”, beraat kavramıyla eş anlamlı değildir; beraat kavramı, daha manidardır.

Arapça “b-r-e” kökünden gelen “beraat” (“berâet”, [براءة]) kavramının **haksızlık** bağlamında iki temel anlamı mevcuttur.

Bu düşüncelerle ki, yeni Ceza Muhakemesi Kanununda hangi hallerde beraat kararının verilebileceği tek tek gösterildikten sonra; kişinin işlemiş bulunduğu suçtan dolayı kusurlu telakki edilmemesi halinde, hakkında beraat kararı değil, “ceza verilmesine yer olmadığı kararı”nın verilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır (CMK, m. 223):

“(1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükmüdür.

(2) Beraat kararı;

a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,

Birinci anlamı, bir haksızlık olarak belirli bir suç işlediği şüphesiyle yargılanan kişinin suç işlemediğinin tespiti halinde, mahkeme hükmüyle bu ithamdan aklanması, temizlenmesi, beri (beri’) kılınmasıdır.

İkinci anlamı ise, kişinin gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla içinde bulunduğu kusurluluk durumundan aklanması, temizlenmesidir.

Bu ikinci anlamda “beraat” (“berâet”) için, kişinin etkin pişmanlık göstermesi gerekmektedir. Etkin pişmanlık için ise en önemli koşul, gerçekleştirilen haksızlığa maruz kalan (kadredilen) kişinin (mağdurun) mağduriyetinin, uğradığı haksızlığın etkilerinin mümkün olduğunca giderilmesidir. Bunun, **kabule** bağlı bir olgu olduğunu gözden ırak tutmamak gerekir. Bu kabul, gerçekleştirilen haksızlık dolayısıyla yaptırımın türünün veya mahiyetinin değişmesi ve hatta, alehtlak yaptırımı maruz kalmamak sonucunu doğurur.

²⁸ Kunter, daha da ileri giderek, işlenen haksızlıktan dolayı kişinin kusurlu telâkki edilmesine rağmen, cezalandırılabilirlik için Kanunun aradığı sair şartların gerçekleşmediği durumlarda da beraat kararının verilmesi gerektiği fikrindedir (KUNTER, Nurullah: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 9. bası, İstanbul, 1989, no. 145).

Türk ceza hukukunda 765 s. mülga TCK’nın yürürlükte bulunduğu 1 Haziran 2005 tarihi öncesinde, objektif cezalandırılabilirlik şartının arandığı suçlarda, bu şart gerçekleşmese dahi, işlenen fiilin “suç” vasfını devam ettirdiği kabul edilmekte idi (DÖNMEZER/ERMAN I, no. 456). Ancak, izlenen suç siyaseti mülahazalarıyla, sözkonusu şartın gerçekleşmediği durumlarda işlenen bu “suç” nedeniyle failin cezalandırılmasına ihtiyaç hissedilmemekte idi. Bu anlayışa sadık kalındığı takdirde, objektif cezalandırılabilirlik şartının gerçekleşmediği durumlarda kişinin sadece cezalandırılmasından sarfınazar edilmesi gerekirdi. Ancak bu dönemin önde gelen ceza hukukçuları Kunter ve Dönmezer/Erman, objektif cezalandırılabilirlik şartının gerçekleşmediği durumlarda, suçun oluştuğunu kabul etmelerine rağmen, fail hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği yönünde görüş dermeyan etmişlerdi (KUNTER, Ceza Muhakemesi Hukuku, no. 40, 145; DÖNMEZER/ERMAN I, no. 461).

Keza, şahsi cezasızlık sebebinin (meselâ yakın akrabalar arasındaki hırsızlık: 765 s. TCK, m. 524) veya cezayı bertaraf eden bir şahsi halin (meselâ rüşvet suçunda suç tamamlandıktan sonra belli şartlarda pişmanlık, faal nedamet: 765 s. TCK, m. 215) mevcudiyeti halinde; işlenen fiil, haksızlık ve dolayısıyla, vasfını muhafaza etmekte, fail de bu fiil dolayısıyla kusurlu telâkki edilmektedir; ancak, yine suç siyaseti gereğince cezalandırmaya ihtiyaç hissedilmediği için, faile ceza verilmemektedir. Bu itibarla, söz konusu hallerde de beraat kararının verilmesi gerekir. CMK, m. 223 hükümleri, bu düşünce doğrultusunda kaleme alınmıştır.

(Kitabımızın 16 ve önceki basılarında bu dipnotta yapılan objektif cezalandırılabilirlik şartlarına ilişkin açıklamalar, 765 s. TCK dönemine ilişkin olup, güncellenmesi yapılmamış açıklamalardır (bkz. 16. bası, sh. 726, dn. 26).

- b) *Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,*
 - c) *Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,*
 - d) *Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması,*
 - e) *Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması,*
- Hallerinde verilir.*

(3) *Sanık hakkında;*

- a) *Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması,*
- b) *Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,*
- c) *Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,*
- d) *Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi,*

*Hallerinde, **kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı** verilir.*

(4) *İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen;*

- a) *Etkin pişmanlık,*
- b) *Şahsi cezasızlık sebebinin varlığı,*
- c) *Karşılıklı hakaret,*
- d) *İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı,*

*Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, **ceza verilmesine yer olmadığı kararı** verilir.*

(5) *Yüklenen suç işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir.*

(6) *Yüklenen suç işlediğinin sabit olması halinde, **belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükümlenir.***

...”

Kusur ilkesi, aynı zamanda **ceza sorumluluğunun şahsiliği** ilkesinin de dayanağını oluşturmaktadır (Anayasa, m. 38, f. 7). “**Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.**” (TCK, m. 20, f. 1)²⁹.

²⁹ Anayasa Mahkemesi, kaçakçılık suçunun işlenişinde kullanılan aracın, sahibinin bu araçla suç işleneceğini, işlenmekte olduğunu **bilmemesine** rağmen, müsadere edilmesini öngören mülga 1918 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükmünü Anayasaya aykırı bulmamıştır: Anayasa Mahkemesi, 14.12.1968, E. 1968/32, K. 1968/62 (RG: 8 Temmuz 1969-13243).

III. Ceza Yaptırımının İnsan Haysiyetiyle Bağdaşır Nitelikte Olması Prensibi

Cezanın temel özelliği, **kişiyi yoksunluğa maruz bırakmaktır**. Ancak, insan haysiyetiyle bağdaşmayan, **kişiyi acı ve ızdırap çekirtmeyi amaçlayan ceza uygulaması yapılamaz**. Tarih sürecinde, suç işleyen kişiye, ceza olarak onu toplum nazarında küçük düşürmeye, rezil rüsvay etmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Keza, ceza olarak, kişinin dayanılamayacak surette acı ve ızdırap çekmesini sağlayacak uygulamalara başvurulmuştur. Bu tür uygulamalar açısından, suçluluğuna kanaat getirilen kişinin yakılması, taşlanması veya linç edilmesi örnek olarak gösterilebilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, teorik olarak ve kanundaki düzenlemeler itibarıyla kimsenin insan onuruyla bağdaşmayan cezaya tabi tutulamayacağı, kural olarak “resosyalizasyon” amacıyla cezalandırma yoluna gidilebileceği kabul edilmekle beraber; ülkedeki ceza infaz kurumlarının içinde bulunduğu şartlar, ceza infazını insan onuruyla bağdaşmaz bir uygulama haline getirebilmektedir. Örneğin toplu halde bulunan mahkumların yemek ve tuvalet ihtiyaçlarının araları duvar-

Yüksek Mahkeme kararında, yurdun ekonomik yapısında önemi küçümsenmeyecek zararlara yol açan kaçakçılığın, malî ve ekonomik türlü tedbirler alınmasına ve suç işleyenler hakkında ağır ceza hükümleri konulmasına rağmen yine de önlenememesi ve yalnız bu suçları işleyenlerin cezalandırılmalarının yeterli olmadığını göz önünde tutan yasa koyucunun, **kimin olursa olsun, kaçakçılıkta kullanılan taşıma araçlarının zor alınma gidilmesini uygun ve etkili bir tedbir** olarak gördüğünü, ... belirtmiştir. İtiraza konu olan (zor alım) hükmü ile kişinin mülkiyet hakkının kullanmasının, belirli nedenlerle sınırlanmış olmasında, kamu yararı bulunduğu ve araç sahibinin tazminat hakkı olduğu gözetildiğinde mülkiyet hakkının özüne dokunmadığı kabul edilmiştir. Diğer yandan araç sahibinin kaçakçılık suçu ile bir ilgisi olmadığı halde taşıtının zor alıma tâbi tutulacağını gösteren 47. maddenin birinci fıkrası hükmüne dayanılarak, başkasının eyleminden taşıt sahibine ceza yükletiliyor gibi bir anlam çıkarılamayacağı, **herhangi bir nedenle taşıtını verdiği kişiyi seçerken gereken dikkat ve özeni göstermemiş olmasından doğan taşıt sahibinin kendi kusurunun bulunduğu** ve bununla meydana gelen sonuç arasında bir illiyet bağı bulunduğu, mal sahibinin iradesi dışında kalan (taşıtın zorla elinden alınması veya çalınması gibi) durumlarda taşıtının, kaçak eşya nakline tahsis edilmiş olması yüzünden kendisine bir sorum yükletilemeyeceği ve bu takdirde zor alıma gidilemeyeceği gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir.

Buna karşılık, Anayasa Mahkemesi, kan gütme saikiyle öldürmelerin ve kan davalarının önüne geçmek amacıyla çıkarılmış olan bir (11.6.1937 tarihli ve 3236 sayılı) Kanunun, kasten ve kan gütme saikiyle öldürme fiilini işleyen, bu fiilin işlenişine iştirak eden kişilerin yanı sıra, suçun işlenişine iştirak etmemiş olan belli derecedeki akrabalarının da, tedbir olarak uzak bir yere gönderilerek orada ikamet ettirilmelerini sağlayan hükümlerini ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir: Anayasa Mahkemesi, 11.2.1964, E. 1963/330, K. 1964/15 (RG: 14 Temmuz 1964-11753). Yüksek Mahkeme, bu kararında **ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin, güvenlik tedbirleri bakımından da geçerli olduğunu** kabul etmiştir.

Keza, Anayasa Mahkemesi, mülga 765 sayılı TCK’nin, basın yoluyla işlenen hakaret suçunda haberi yapanın isnadı ispat edememesi dolayısıyla hakkında cezaya hükmedilmenin yanı sıra, süreli yayın sahibinin veya yayınlayanın da ceza hukuku bakımından sorumluluğunu öngören hükmünü (m. 481, f. 8) ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir: Anayasa Mahkemesi, 19.9.1991, E. 1991/2, K. 1991/30 (RG: 16 Eylül 1992-21347).

la bölünmemiş aynı fiziki ortamda karşılanması şeklindeki infaz koşullarının insan onuruyla bağdaştığını söylemek mümkün değildir. Keza, infaz kurumunda cezasını çekmekte olan hükümlülerin doğal ihtiyaçlarının meşru zeminde karşılanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmamasının, cezanın infazını insan haysiyetiyle bağdaşır olmaktan çıkardığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle, ceza infaz kurumlarında mahkumlara karşı gerçekleştirilen muamelelerin, insan onuruyla bağdaşır mahiyette olmasına özen gösterilmelidir. Unutmamak gerekir ki, cezalandırmakla kural olarak kişinin işlediği suçtan dolayı faal pişmanlık duyarak tekrar topluma kazandırılması amacı güdüldüğüne göre; bu amaç ancak mahkumların insan onuruyla bağdaşır bir muamele biçimine tabi tutulmasıyla gerçekleştirilebilir.

Türkiye, taraf olduğu Milletlerarası Sözleşmelerde insan onuruyla bağdaşmayan ceza uygulamalarının yasak olduğunu kabul ederek, bu uygulamaların önlenmesiyle ilgili gerekli tedbirleri alma konusunda taahhüt altına girmiştir.

Türkiye'nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde ilân edilen “*İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi*”nin 5. maddesine göre;

«Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsanî, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tâbi tutulamaz.»

Keza, Birleşmiş Milletler “*Medenî ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme*”ye göre;

“Hiç kimse işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya maruz bırakılamaz.” (m. 7, birinci cümle)

“*İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme*”nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin) 3. maddesine göre;

«Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsanî yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tâbi tutulamaz.»

“*İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi*”ne taraf devletler, işkenceyi, diğer zalimane, gayri insani ve küçük düşürücü muamele veya cezalandırmayı yasaklamak konusunda taahhüt altına girmişlerdir. Sözleşmede, bu tür uygulamaların hiçbir hal ve şartta meşru ve mazur gösterilemeyeceği hüküm altına alınmıştır (m. 2, f. 2, 3; m. 16). Ayrıca, taraf devletlere bu tür uygulamaların suç olarak tanımlanması yönünde bir yükümlülük tahmil edilmiştir (m. 4; m. 16).

Türkiye, “*İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi*”ni onaylamak suretiyle de aynı yükümlülükleri teyid etmiş bulunmaktadır.

Bu milletlerarası yükümlülüklerle paralel olarak Anayasada da insan onuruyla bağdaşmayan ceza uygulamalarının yasak olduğu kabul edilmiştir:

«Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.» (m. 17, f. 3).

Ekskurs 1. Kur'an'daki Ceza ile İlgili Hükümlerin Günümüz Hukuk Anlayışına Aktarılması

I. “Ceza” kavramı Kur'an'da, sadece haksızlık oluşturan fiiller karşılığında uygulanan yaptırımı ifade zımında kullanılmış değildir. Çeşitli ayetlerde hukuka uygun olan bir fiil dolayısıyla failin **ödüllendirilmesi** bağlamında da ceza kavramına yer verilmiştir³⁰. Bazı ayetlerde ceza ibaresi, **karşılık**³¹ anlamında³²; **iyi veya kötülüğün karşılığı** olarak³³, iyi veya kötü yönde çabanın karşılığı anlamında³⁴ kullanılmıştır.

Bu itibarla ceza, bir **haksızlık karşılığında** uygulanan bir **yaptırım** anlamına da gelmektedir. Ancak, bu bağlamda söz konusu ibare, münhasıran ceza hukuku yaptırımını değil, genel olarak bir haksızlık karşısında uygulanan, uygulanabilecek olan bütün yaptırımları ve dolayısıyla, **tazminatı** da kapsayacak geniş bir anlam içeriğine sahiptir³⁵.

Bu çalışma kapsamındaki açıklamalar, münhasıran suç oluşturan haksızlık karşılığında uygulanan ve pozitif hukuk metinlerinde dar anlamda ceza olarak tavsif edilen yaptırımlara ilişkin olacaktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kişinin gerçekleştirdiği bir haksızlık dolayısıyla Allah tarafından cezalandırmasıyla kamu otoritesi (Devlet) tarafından cezalandırılması arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Allah'ın cezalandırması, esas itibarıyla insanın bu dünya hayatından ayrılmasından sonra³⁶ söz konusu ise de, bu dünyada da gerçekleşebilir. Allah'ın bu dünyadaki cezalandırması, tüm topluma da şamil olabilir³⁷.

³⁰ İbrâhîm [14], Ayet 51; Tâha [20], Ayet 15, 76; Zümer [39], Ayet 34; Kamer [54], Ayet 14, 35. Keza, “*sevâb*” ibaresi de benzer anlamlarda kullanılmıştır: Âl-u İmrân [3], Ayet 148, 195; Muttaffîfîn [83], Ayet 36.

³¹ **Karşılık** anlamında, “*ecr*” kelimesi de kullanılmıştır: Tûr [52], Ayet 40.

³² Tûr [52], Ayet 16; Rahmân [55], Ayet 60.

³³ Necm [53], Ayet 31.

³⁴ Necm [53], Ayet 39.

³⁵ Bkz. Bakara [2], Ayet 48.

³⁶ **Allah**, meşru yolla elde edilmiş olan malvarlığına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmekte ısrar eden kişilerin malvarlığını heba etmek suretiyle, onları **daha dünyada iken de cezalandırmaktadır** (Kalem [68], Ayet 17 ilâ 33).

³⁷ Hâkka [69], Ayet 4 ilâ 10.

Haksızlık yapana, kamu otoritesi tarafından bu sebeple yaptırım uygulansa bile, Allah nezdindeki sorumluluğu devam eder. Keza, insanın işlediği suç sebebiyle Allah nezdinde cezalandırılacak olması, devlet tarafından cezalandırılmasını gereksiz kılmaz³⁸.

Allah'ın cezalandırmasıyla, devletin cezalandırmasını birbiriyle karıştırmamak gerekir. Allah'ın cezalandırması bağlamında, “**intikam**” ibaresi kullanılır³⁹; Allah'ın insanı örneğin ateşte **yakarak** cezalandıracağı ve cezasının **ebedî** olabileceği yani zamanla sınırlı olmayabileceği beyan edilir⁴⁰.

Oysa kamu otoritesi tarafından cezalandırmada, işkence ve eziyet uygulanamaz ve dolayısıyla, suçluya acı çektirilemez, suçlu yakılarak cezalandırılmaz. Bu itibarla, Allah'ın cezalandırmasına ilişkin Kur'an beyanlarından, devletin uygulayacağı ceza hukuku yaptırımları bağlamında bir sonuç çıkarılamaz. Bu nedendir ki, **ceza hukuku yaptırımları, haksızlığı gerçekleştiren kişiden intikam almak, öç almak amacını taşıyamaz.**

Ancak bir fiil sebebiyle uygulanabilen ve bir fiilin karşılığını oluşturan ceza⁴¹ yaptırımı, **ölçülü**, yani kişinin işlediği fiilin haksızlık derecesiyle **orantılı** olmalıdır ve orantılı olarak uygulanmalıdır⁴².

Ceza sorumluluğu şahsîdir⁴³. Bu ilke, insanın Allah nezdindeki sorumluluğu için geçerli olduğu gibi, ceza hukuku yaptırımları ile ilgili olarak da dikkate alınmalıdır. Buna karşılık, söz konusu ilke, bir özel hukuk yaptırımı olan tazminat sorumluluğu bakımından dikkate alınmaz. Tazminat sorumluluğu bakımından geçerli olan müşterek ve müteselsil sorumluluk, ceza sorumluluğu bakımından söz konusu değildir⁴⁴.

II. Ceza hukuku yaptırımlarının özelliği, infazıyla, uygulanmasıyla, kişinin etkin pişmanlık göstermesinin yanı sıra, toplumsal fayda sağlanmasının amaç-

³⁸ Qehf [18], Ayet 87.

³⁹ Duhân [44], Ayet 16.

⁴⁰ Ahiret sorumluluğunun ağırlığına işaret zımında, bugünün “*şerri*”nden (İnsân [76], Ayet 7, 11) “*kötülüğü*”nden (Nahl [16], Ayet 27) söz edilmiştir.

⁴¹ Yâsîn [36], Ayet 54.

⁴² Nahl (16), Ayet 126; Kasas (28), Ayet 84. Ceza yaptırımı, kişiye bir haksızlık, kötülük yapılmasını ifade etmez. Ancak, suç ile ceza arasındaki **orantıya** işaret zımında cezanın kişiye uygulanan, gerçekleştirdiği haksızlığın misliyle “*kötülük*” olduğu ifade edilmiştir: Şûrâ (42), Ayet 40.

⁴³ En'âm (6), Ayet 164; İsrâ (17), Ayet 13, 15; Fâtır (35), Ayet 18; Zümer (39), Ayet 7; Tûr (52), Ayet 21; Necm (53), Ayet 37-41. Ayrıca bkz. Yûsuf (12), Ayet 79.

⁴⁴ Bir haksızlığı iştirak halinde gerçekleştiren kişilerin bu haksızlıkla sebebiyet verdikleri zararı karşılama hususunda müşterek sorumludurlar. Müşterek sorumluluk, haksızlığı gerçekleştiren kişilerin kendi aralarında söz konusudur. Müteselsil sorumluluk, ise, mağdurun, birden fazla kişi tarafından iştirak halinde gerçekleştirilen bu haksızlık sebebiyle uğradığı zararı bu kişilerin her birinden tamamıyla tazmin etme yetkisini ifade etmektedir.

lanmasıdır. Şayet yaptırım uygulanmasıyla sosyal adaletin tesisine bir katkı sağlamaya yönelik yaptırım uygulama imkânı bulunmuyorsa, kişi üzerinde bireysel etki doğuracak yaptırım uygulanmasıyla yetinilebilmektedir. Kısacası, yaptırımın infazıyla, uygulanmasıyla kişilerde **uyarı** fonksiyonu icra etmesi⁴⁵, **sorumluluk duygusunun** gelişmesinin ve diri tutulmasının sağlanması amaçlanmaktadır⁴⁶. Bu itibarla, kötülüğe **iyilikle** karşılık vermek⁴⁷, kötülüğü iyilikle savmak⁴⁸, ceza siyasetinin temelini oluşturmaktadır.

İlâhî Öğreti insana, bir haksızlık gerçekleştiren kişiye, kendisi, haksızlığa uğrayan ve hatta bütün toplum bakımından **yararlı** olabilecek yaptırım uygulanmasını emretmektedir⁴⁹. İlâhî Öğreti, herhangi bir kişiye yararı olmayan bir yaptırım uygulamasına asla izin vermemektedir.

Uygulanacak olan yaptırımın haksızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde, etkin pişmanlık göstermesini sağlamaya yönelik efektif bir uyarı etkisi meydana getirmesi, yararlılık bakımından dikkate alınması gereken ölçütlerden birini oluşturmaktadır⁵⁰.

İlgili suç tanımındaki cezaya seçenек yaptırımlar, yararlılık bakımından etkisine göre, ağırdan hafife doğru ve özellikle kişinin yerine getirme gücü dikkate alınarak sıralanmalıdır.

Gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla hakkında uygulanacak olan cezaya seçenек yaptırım türünün belirlenmesinde, kişinin bunun gereklerini yerine getirme imkân ve iktidarına sahip olması, önemli bir değerlendirme ölçütü olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, haksızlığı gerçekleştiren kişi hakkında uygulanacak olan cezaya seçenек yaptırımın, imkân ve iktidarı göz önünde bulundurularak, ağırdan hafife doğru sıralanmış olan yaptırım türleri arasındaki sıraya göre belirlenmesi gerekmektedir.

Gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla uygulanacak olan yaptırımın belirlenmesinde kişinin koşulları göz önünde bulundurulacaktır⁵¹.

Geleneksel “fıkıh” kaynaklarında “**kıyas**”ın bir “ceza” olduğu kabul edilmektedir. Oysa kanaatimizce, “kıyas” bir ceza değil, cezanın uygulanması bağlamında bir **ilkeyi** ifade etmektedir. Ceza, kişiye gerçekleştirdiği haksızlığın **misliyle**

⁴⁵ Mâide [5], Ayet 38; Mücadele [58], Ayet 3-4.

⁴⁶ Mâide [5], Ayet 95.

⁴⁷ Fussilet [41], Ayet 34.

⁴⁸ Ra’d [13], Ayet 22; Mu’minûn [23], Ayet 96.

⁴⁹ Bakara (2), Ayet 178; Nisâ’ (4), Ayet 92; Maide (5), Ayet 89.

⁵⁰ Maide (5), Ayet 39.

⁵¹ Maide (5), Ayet 95.

mukabele etmektedir⁵². Kur'an'da, haksızlık karşısında “**kıyas**” (“**misliyle mukabele**”) **esasına uygun** olarak **yaptırım** uygulamasının toplum barışının devamlılığı bakımından önemine işaret edilmiştir⁵³. Bu itibarla örneğin kasten öldürme ve kasten yaralama fiilleri karşılığında, “**kıyas**” (“**misliyle mukabele**”) **esasına uygun** olarak **yaptırım** uygulanacaktır⁵⁴.

Günümüzde, kanunlarda suç karşılığında dar anlamda ceza olarak, hapis cezası ve adli para cezası gibi cezalara yer verilmektedir. Bu bağlamda cezanın genel önleme etkisi söz konusudur. Ancak, muayyen bir suçun işlenmesi sebebiyle somut olayda örneğin hapis cezasına hükmedilmekle birlikte, belirli koşullara bağlı olarak bu cezanın infaz kurumunda çektirilmesinden kısmen veya tamamen sarfınazar edilebilmesinin yolu açık tutulmaktadır. Hükümlü, gerçekleştirdiği bir haksızlık dolayısıyla içinde bulunduğu kusurluluk durumundan arınması, suç işlemek suretiyle bozduğu toplumsal barışın yeniden tesisi, sebebiyet verdiği zararların tazmini, işlediği suç sebebiyle kaybettiği güveni yeniden ictisabı, kısacası resosyalizasyonu için, kendi koşullarına uygun olarak belirlenen **yükümlülükleri (edim)** yerine getirdiği takdirde, hakkında hükmolunan cezanın infaz kurumunda çektirilmesinden kısmen veya tamamen sarfınazar edilebilmelidir. Bir **kefare**t⁵⁵ olarak belirlenen bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, hükmolunan **ceza infaz edilmiş** sayılmalıdır.

Bu yaptırım sistemi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde hükümlünün **denetim ve gözetim** altında tutulmasını gerekli kılmaktadır. Bu denetim ve gözetimin etkinliğinin sağlanabilmesi için, **doğrudan ve birebir** olması gerekmektedir (**denetimli serbestlik tedbiri**).

İşaret etmek gerekir ki, işlediği suç sebebiyle hükmolunan cezanın, kefare olarak belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi suretiyle infazının öncelikle, faille mağdur arasında barışmayı sağlamak ve dolayısıyla, failin topluma yeniden kazandırılması amacına hizmet edecek mahiyet taşıması gerekir. Zira, faille mağdur arasında barışmayı temin etmeyen veya edemeyen bir yaptırım sisteminin toplum barışına katkı sağlaması ve suçlunun yeniden topluma kazandırılması amacına hizmet etmesi beklenemez.

⁵² Şu'ara [28], Ayet 40; Mü'min [40], Ayet 40.

⁵³ Bakara [2], Ayet 179.

⁵⁴ Bakara (2), Ayet 178; Mâide (5), Ayet 45. Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *İnsan Öldürme İle İlgili Kur'an Hükümlerinin Günümüz Ceza Hukuku Düşüncesine Aktarılması*, in: Dr.Dr.h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan (Editörler: F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoğlu, A. Sözüer, F. Turhan), Ankara, Mayıs 2018, sh. 503 vd.

⁵⁵ Kefaretin yerine getirilmesi, haksızlığı örten bir sonuç doğurmaktadır (Fetih [48], Ayet 5). Kefaret olarak, haksızlığı gerçekleştiren kişi, durumuna göre alternatif yükümlülüklerden birini yerine getirebilir. Hatta bu alternatif yükümlülükler, kademelendirilebilir (Bkz. Nisâ' [4], Ayet 92; Maide [5], Ayet 33, 95; Mücadele [58], Ayet 3, 4. Ayrıca bkz. Bakara [2], Ayet 196).

Bir haksızlığın karşılığı olarak **yaptırımın** belirlenmesinde ve uygulanmasında **misliyle mukabele**⁵⁶ esas ise de; **ceza** siyaseti bakımından kötülüğe karşı **iyilikle mukabele** etmek tavsiye edilmiş⁵⁷; **uzlaşma** ve **af**, övgüye layık görülmüştür⁵⁸.

Bu nedenle, hükmolunan cezanın kefarete olarak belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi suretiyle infazı için, suçun **mağdurunun rızasının** aranması şarttır.

III. Ceza hukukunda etkin pişmanlık, suç tamamlandıktan sonra, failin pişmanlık duyarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sağlamasını veya mağdurun mağduriyetini mümkün olduğunca gidermesini ifade etmektedir. Belirli suçlar bakımından kabul edilen etkin pişmanlık halinde, ilgili suça ve etkin pişmanlığın gösterildiği zamana göre, fail hakkında verilecek cezada indirim yapılması ve hatta, cezaya hükmedilmemesi yoluna gidilebilmektedir⁵⁹.

Etkin pişmanlık, gerçekleştirilen haksızlığı gerçekleştirilmemiş duruma irca etmez, geri döndürmez. Gösterilen pişmanlığın etkinliğinden söz edebilmek için, kişinin, haksızlık gerçekleştirmekle sebebiyet verdiği mağduriyeti mümkün olduğunca giderecek bir çaba göstermesi gerekir. Gerçekleştirilen **her haksızlık** dolayısıyla etkin pişmanlıkta bulunulabilir. Ancak bu pişmanlık, esas itibarıyla, yaptığı yanlışlık dolayısıyla pişmanlık gösteren ile Rabbi arasında bir meseledir⁶⁰. Ancak, Ceza hukukunda etkin pişmanlık ilgili suç bakımından özel bir hüküm yok ise, sadece sonuç cezanın belirlenmesinde takdirî indirim nedeni olarak dikkate alınabilir.

Etkin pişmanlıktan söz edebilmek için, kişinin;

- 1) haksızlığı “cahillikle” yapmış olması,
 - 2) yaptığından dolayı affını dilemesi ve bir daha yapmama konusunda söz vermesi,
 - 3) verdiği söze sadık kalarak, aynı yanlış yapmamakta sebat etmesi,
- gerekmektedir⁶¹.

Etkin pişmanlık gösterdiğinin kabulü için, kişinin gerçekleştirdiği haksızlığın idrakine vararak affını dilemesi, geleceğe matuf olarak bir daha aynı veya farklı

⁵⁶ Yûnus [10], Ayet 27; Mu'min [40], Ayet 40; Şûrâ [42], Ayet 40.

⁵⁷ Fussilet [41], Ayet 34.

⁵⁸ Şûrâ (42), Ayet 40. Haksızlık ve suçluluk karşısında insana daima hoşgörü ve affedicilik öğütlenmiştir: Mâide (5), Ayet 13. Ayrıca bkz. Hicr (15), Ayet 85.

⁵⁹ Bkz. Tâha [20], Ayet 122, 123. Kur'an'da pek çok hükümde, haksızlık gerçekleştiren kişinin, pişmanlık göstererek mağdurla barışması, uzlaşması halinde, ceza hukuku sorumluluğundan sarfınazar edilebileceği kabul edilmektedir. Örneğin hırsızlık bakımından, Maide [5], Ayet 39; hakaret bakımından, Hucurât [49], Ayet 11.

⁶⁰ Nisâ' (4), Ayet 116.

⁶¹ Bkz. Nahl [16], Ayet 119.

bir haksızlık gerçekleştirmeme doğrultusunda tutum ve davranışlarını düzeltmesi ve bunu açık bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir⁶².

Pişmanlık sadece soruşturma ve kovuşturma sürecinde değil, hükmolunan cezanın infazı sürecinde de gösterilebilir. İnfaz kurumundaki hükümlü, “*keşke ahlâkın ve hukukun gereklerine uygun davransaydım da bu ortamda bulunmasaydım*” duygusunu yaşamalıdır⁶³. Hükümlü, yaptığına yanlış olduğunu idrakine vararak, konulduğu infaz kurumundan bir an evvel çıkabilmek için yol ve çare arayışı içine girmelidir⁶⁴. Ceza ve infazı, hükümlüye “keşke” dedirtebilecek bir etkinliğe sahip olmalıdır⁶⁵. Bu itibarla, mağdurla barışmasını sağlamak amacıyla ve mağdurun kabulüne bağlı olarak, hükümlünün bazı edimleri yerine getirmesi koşuluyla mahkûm olduğu cezanın infaz sureti değiştirilebilmelidir.

IV. Kasten öldürme suçunda öldürülenin yakınları⁶⁶, mahkeme huzurunda fail hakkında kısas esasına dayalı ceza uygulanmasından sarfınazar edilmesi, yani belirli bir koşula bağlı olarak veya alelittlak **failin affedilmesi** yönünde **irade** açıklama hususunda **yetkili** kılınmışlardır.

Kanaatimizce, bu bağlamda önce **öldürülen kişi üzerinde** varsa **velayet** veya **vesayet yetkisini haiz kişiler** tezekkür edilmelidir.

Öldürülen üzerinde bir başkasının velayet veya vesayetinin bulunmadığı hallerde ise, **akrabalık ilişkisini** dikkate alarak, faili affetme yetkisini haiz kişiyi veya kişileri belirlemek gerekir. Buna göre örneğin, öldürülenin birinci derece kan hısımları (alt ve üst soyu, usul ve fûruu) ile eşinin; bunların bulunmaması halinde ise, ikinci derece kan hısımlarının bu yetkiyi kullanabilmesi gerekir⁶⁷.

Bu nedenledir ki, suçun mağduru hayatta olduğu sürece, **devletin mağdura rağmen suçluyu affetme yetkisinin olmaması gerekir**. Devlet, ancak toplumu oluşturan herkesin mağdur edildiği, mağduru muayyen bir kişi olmayan suçlardan dolayı suçluyu affetme yetkisi ile donatılmalıdır. Affa rağmen fiil suç olmaya devam ettiği için, bu affetmenin mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırmaması gerekir. Bu itibarla af, alelittlak değil, **belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluna** hamledilmelidir.

IV. Ölüm Cezası

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayılı Kararı ile kabul edilip, Türkiye tarafından 15 Ağustos 2000 tarihinde im-

⁶² Bakara [2], Ayet 160.

⁶³ Bkz. Mulq [67], Ayet 10.

⁶⁴ Bkz. Mu’min [40], Ayet 11.

⁶⁵ Fâtır [35], Ayet 37; Zümer [39], Ayet 58.

⁶⁶ Bu bağlamda Kur’an’da “*öldürülenin kardeşi*” (Bakara [2], Ayet 178), “*öldürülenin velisi*” (İsrâ [17], Ayet 33), öldürülenin “*ehli, ailesi*” (Nisâ’ [4], Ayet 92) ibareleri kullanılmıştır.

⁶⁷ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Silvia Tellenbach’a Armağan, sh. 503 vd.

zalanmış ve **4.6.2003 tarihli ve 4868 sayılı Kanuna** istinaden onaylanmış olan “**Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme**”nin⁶⁸ 6. maddesinde, *yaşama hakkı* güvence altına alındıktan (f. 1) sonra;

“Ölüm cezası kaldırmamış olan ülkelerde, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan hukuka uygun olarak ve bu Sözleşme ile Soykırım Suçunun önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin hükümlerine aykırı olmayacak biçimde, sadece çok aşırı suçlar için ölüm cezası verilebilir. Bu ceza sadece yetkili mahkeme tarafından verilen nihai karardan sonra infaz edilebilir.” (f. 2)

“Yaşı on sekizden küçük olan kimselere işledikleri suçlar nedeniyle ölüm cezası verilemez; hamile kadınların ölüm cezaları infaz edilemez.” (f.5)

hükümlerine yer verilmiştir.

25.5.1984 tarihinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından kararlaştırılan (Karar no: 1984/50) metne göre, ölüm cezası kaldırılmamış olan ülkelerde sadece “*ağır suçlar*” için ölüm cezasına hükmedilebilmelidir. Bu ağır suçlar, ancak *kasten işlenen adam öldürme* veya “*çok ciddi sonuçlar doğuran diğer suçlar*” olabilir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 15 Aralık 1989 tarih ve 44/128 sayılı kararı ile kabul edilen “*Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Andlaşma*”ya ek “*Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan İkinci Seçmeli Protokol*”ün Birleşmiş Milletler Genel kurulundaki oylanmasına Türkiye katılmamış⁶⁹ ve henüz bu Protokolü imzalamamıştır.

Halen 43 devlet tarafından imzalanmış olan bu Protokol, son olarak Azerbaycan (22.1.1999), Bulgaristan (11.3.1999), Ermenistan (22.3.1999) ve Büyük Britanya Bileşik Krallığı (31.3.1999) tarafından imzalanmıştır. Bu Protokole bazı devletler çekince koymuşlardır.

Bu Protokol, barış zamanı ve savaş zamanı ayırımı yaparak, barış zamanında ölüm cezasının kaldırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20.11.1989 tarihinde kabul edilen “**Çocuk Hakları Sözleşmesi**”nde “*Onsekiz yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası (ve keza,) salıverme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası verilmeyece*”ği hüküm altına alınmıştır (m. 37, bend a, cümle 2)⁷⁰.

⁶⁸ Söz konusu Sözleşme metni için bkz. RG: 18 Haziran 2003/25142. Sözleşmenin Prof. Dr. Öztekin TOSUN tarafından yapılan Türkçe tercümesi için bkz. Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, yıl 7, sayı 10, 1973, sh. 283 vd.

⁶⁹ Bilgi için bkz. GEMALMAZ, Mehmet Semih: *Türkiye’de Ölüm Cezası*, cilt I, İstanbul, Ocak 2001, sh. 190.

⁷⁰ Türkiye bu Sözleşmeyi 9.12.1994 tarih ve 4058 sayılı Kanunla onaylamıştır. Sözleşme metni için bkz. RG.: 27.1.1995/22184.

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 28 Nisan 1983 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz adına 15 Ocak 2003 tarihinde Strazburg’da imzalanan “*11 No’lu Protokol ile Değişik, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi’ne Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 No’lu Protokol*”un onaylanması **26.6.2003 tarihli ve 4913 sayılı Kanunla** uygun bulunmuştur⁷¹. Söz konusu Protokolde;

“Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.” (m. 1)

“Bir Devlet, savaş zamanında veya yakın savaş tehdidi durumlarında işlenen eylemler için yasalarında ölüm cezasına ilişkin hüküm öngörebilir; böyle bir ceza, ancak, yasa da belirtilen durumlarda ve yasa hükümlerine uygun olarak uygulanabilir.” (m. 2)

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu Protokole göre, ölüm cezası yasağı “barış zamanı”na münhasırdır. Bu itibarla, “bir Devlet **savaş zamanında** veya **yakın savaş tehdidi durumlarında işlenen eylemler** için yasalarında ölüm cezasına ilişkin hüküm öngörebilir; böyle bir ceza, ancak, yasa da belirtilen durumlarda ve yasa hükümlerine uygun olarak uygulanabilir.” (m. 2).

Ancak, söz konusu Protokolde, taraf olan “her devlet, imza anında veya onaylama, kabul yahut uygun bulma belgesini tevdi ederken bu Protokolün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtir.” hükmüne yer verilirken (m. 5, birinci fıkra), ölüm cezası yasağına ülke olarak sınırlama getirilebilmesine imkan tanınmıştır.

Keza, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 3 Mayıs 2002 tarihinde Vilnius’da imzaya açılan ve Türkiye tarafından 9 Ocak 2004 tarihinde Strazburg’da imzalanan “*İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol*”ün onaylanması **6.10.2005 tarihli ve 5409 sayılı Kanunla** uygun bulunmuştur⁷². Bu Sözleşme ile Avrupa Konseyi üyesi devletler, “**ölüm cezasının her durumda kaldırılması için nihaî adımı atmaya karar ver**”mişlerdir.

Söz konusu Protokole göre;

“Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.” (m. 1)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29.11.1985 tarih ve 40/33 sayılı kararı ile kabul edilen “*Küçükler Hakkındaki Adalet Sistemine İlişkin Asgari Standart Kurallar*” (**Beijing Kuralları**) içeriğinde, küçüklere işledikleri hiçbir suç nedeniyle ölüm cezası verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır (m. 17, f. 2).

⁷¹ Söz konusu Ek 6 No’lu Protokol metni için bkz. RG.: 01 Temmuz 2003/25155.

⁷² Söz konusu Ek 13 No’lu Protokol metni için bkz. RG.: 12 Ekim 2005/25964.

“... bu Protokolün hükümlerine **istisna getirilmeyecektir.**” (m. 2)

“... bu Protokolün hükümleriyle ilgili hiçbir çekince konulamaz.” (m. 3)

Ancak, söz konusu Protokolde, taraf olan “her devlet, imza anında veya onaylama, kabul yahut uygun bulma belgesini tevdi ederken bu Protokolün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtir.” hükmüne yer verilirken (m. 4, birinci fıkra), ölüm cezası yasağına ülke olarak sınırlama getirilebilmesine imkan tanınmıştır.

Anayasanın 38'inci maddesinde, **7.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Kanunla** yapılan değişiklikle, herhangi bir istisna öngörülmezsizin “**Ölüm cezası ... verilemez.**” (f. 10) hükmüne yer verilmiştir⁷³.

Anayasada yapılan bu değişiklikten sonra, kanunlarda yer alan çeşitli suçlar karşılığında öngörülen ölüm cezası, **14.7.2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülmüştür**⁷⁴. Yeni TCK'da da ölüm cezasına yer verilmemiştir.

⁷³ Birçok devlet anayasasında ölüm cezasının kaldırıldığına dair hükümlere yer verilmiştir. (Almanya, m. 102; İspanya, m. 15; Avusturya, m. 85).

⁷⁴ Doktrinde ölüm cezasının lehinde ve aleyhinde görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşler, özetle şu şekildedir:

Ölüm cezasına taraftar olan görüşler:

Ölüm cezası, kasten adam öldürme gibi ağır suçlar açısından en etkili cezadır.

Ömür boyu hürriyeti bağlayıcı cezaya (müebbet ağır hapis cezasına) mahkûm olan kişilerin tekrar topluma kazandırılması imkanı çoğu zaman bulunmamaktadır. Aksine, böyle bir cezaya mahkûm olup cezası infaz edilen kişi tamamen toplumdan kopmakta, toplumsal ilişkilerden uzaklaşarak, yalnızlığı tercih eden, insanlardan kaçan bir kişiliğe kavuşmaktadır. Bu nedenle, ölüm cezasının alternatifi olarak ileri sürülen ömür boyu hürriyeti bağlayıcı ceza uygulaması, aslında cezalandırmakla güdülen amacı çoğu zaman gerçekleştirememektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, bütün suçluların ceza infazı sırasında uygulanan tretman sonucunda işledikleri suçtan dolayı faal pişmanlık duyarak resosyalize edildiklerini ileri sürme de bir hayalden ibarettir. Bu nedenle, belirli nitelikte suçları işleyen kişilerle ilgili olarak uygulanan ceza yaptırımları, bu kişilerin toplumdan tasfiye edilmesi amacına yönelik olmalıdır.

Ölüm cezasının, kasten adam öldürme gibi belli ağırlık derecesindeki suçları işleyen kişilerin toplumdan tasfiyesi amacına yönelik bir yaptırım olarak muhafaza edilmesi gerektiği savunul gelmiştir.

Keza, kasten adam öldürme gibi ağır suçlar açısından kanunda öngörülen ölüm cezasının, cezanın genel önleme fonksiyonu açısından daha etkili bir yaptırım olduğu da ifade edilmiştir.

Ölüm cezasına karşı olan görüşler.

Ölüm cezası, insan onuruyla bağdaşmaz. İşlediği suç dolayısıyla çok tehlikeli bir kişiliğe sahip olduğu ortaya çıksa bile, suçlu yine bir insandır ve insan onuruna sahiptir.

Ceza muhakemesinde hatalı sonuçlara varılabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. Ceza muhakemesinde yapılan bir yanlışlık sonucunda verilen ölüm cezasının infazı durumunda, bu yanlışlığın giderilmesine artık imkân bulunmamaktadır.

Ne derece ağır olursa olsun bir suçun işlenmiş olması dolayısıyla Devlet kişinin hayatına son verememelidir.

Ölüm cezası, cezanın özel önleme amacının inkarı niteliği taşımaktadır

Bu kabule bağlı olarak, **bir başka devlet tarafından ölüm cezasını gerektiren bir suç sebebiyle Türkiye’den iade talebinde bulunulması halinde, bu talebin kabul edilmeyeceği kanunla hüküm altına alınmıştır: 23.4.2016** tarihli ve 6706 sayılı *Cezaî Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu*⁷⁵.

V. Hapis Cezası

19. yüzyıl ceza hukuku düşüncesinde suçlar ağırlıklarına göre “*cürüm*”, “*cünha*” ve “*kabahat*” olarak derecelendirmeye tabi tutulmuştu⁷⁶. Bu derecelendirmeye paralel olarak, hürriyeti bağlayıcı cezalar “*ağır hapis*”, “*hapis*” ve “*hafif hapis*”

Ölüm cezasının belli ağırlık derecesindeki suçların işlenmesi açısından korkutucu olduğu yönündeki düşünceler tutarlı değildir. Özellikle ihtirasi suçlular ile siyasi nitelikte suçları işleyen kişiler açısından ölüm cezasının caydırıcı bir etkisinin olduğu söylenemez.

Ölüm cezası, suçluyu toplumdan tasfiye amacı gütmektedir. Tasfiye, çağdaş bir cezanın amacı olamaz. Çağdaş bir ceza, suçlunun topluma kazandırılmasını, ıslahını ön planda tutmaktadır.

⁷⁵ RG: 5 Mayıs 2016 / 29703.

⁷⁶ Eski kanunlarda bu konuda üçlü ayırım kabul edilmekteydi. Buna göre suçlar, *cürüm*, *cünha* ve *kabahat* olarak üçe ayrılmaktaydı. Meselâ, 1810 Fransız (Napolyon) Ceza Kanununda (m. 1) bu ayırım benimsenmişti. Büyük ölçüde bu Kanundan iktibas edilen 1274 (1868) Osmanlı Ceza Kanunname-i Hümayunu’nda da bu ayırım benimsenmişti.

1871 Alman Ceza Kanununda, başta bu üçlü ayırım benimsenmişti. Fakat, kabahatleri ceza hukuku anlamında suç olmaktan çıkarma eğiliminin etkisiyle, 1975 yılında bu Kanunda yapılan değişiklikle, kabahat türünden olan suçlar, ceza kanunundan çıkarılmıştır. Bu fiiller, Alman hukukunda “*düzene aykırılıklar*” olarak nitelendirilerek, sadece idarî ceza yaptırımını (idarî yaptırım) uygulanmasını gerektiren fiiller olarak tanımlanmışlardır. Bu gün Alman Ceza Kanununda suçlar *cürüm* ve *cünha* olmak üzere iki grupta tasnif edilmiştir.

765 s. TCK’nda ise, mehaz (kaynak) 1889 İtalyan CK’nda olduğu gibi, suçlar *cürüm* ve *kabahat* olarak iki grupta tasnif edilmişti. Kanun, “Kitap” olarak ifade edilen üç ana bölümden müteşekkildi. “*İkinci Kitap*” cürümlere ayrılmış iken, “*Üçüncü Kitap*”ta kabahatler yer almaktaydı. Yeni TCK’na ilişkin Hükümet Tasarısında da cürüm ve kabahat ayırımına sadık kalınmıştı. Ancak, Tasarıda, kabahatleri ceza hukuku anlamında suç olmaktan çıkarma eğiliminin etkisiyle, bazı kabahatlerin adli nitelikte suç olmaktan çıkarılması düşüncesi benimsenmişti. 765 s. Kanunun 527, 529, 531, 533-535, 538-545, 548, 550, 556-562, 570, 575-581 ve 584. maddelerinde “kabahat” türünden suç olarak tanımlanan fiiller, Tasarıda suç olmaktan çıkarılmıştı. 765 s. TCK’nda “kabahat” türünden suç olarak tanımlanan dilencilik fiilleri (m. 544, 545) ile akıl hastaları üzerindeki nezaret görevinin gereklerinin yerine getirilmemesi (m. 560 – 562), Hükümet Tasarısında suç olmaktan çıkarılmıştı.

Keza, belirtmek gerekir ki, Hükümet Tasarısında, kabahatler, ayrı bir bölüm altında değil, cürümlerin arasına serpiştirilmek suretiyle tanımlanmışlardı. Hükümet Tasarısında, yürürlükte olan Kanunda “kabahat” olarak düzenlenen bazı suçlar, “cürüm” olarak tanımlanmıştı.

765 s. TCK’nda “kabahat” türünden suç olarak tanımlanmış olan bazı fiiller, Hükümet Tasarısında da bu özelliğini muhafaza etmekteydi. Örneğin 765 s Kanunun 530 uncu maddesinde tanımlanan “kabahat” türünden suç, Hükümet Tasarısında 472’nci maddede dili sadeleştirilerek yine “kabahat” türünden suç olarak tanımlanmıştı.

Bazı fiiller, 765 s. TCK’da “kabahat” türünden suç olarak tanımlanmış iken, Hükümet Tasarısında “cürüm” türünden suç olarak tanımlanmıştı. Örneğin 765 s. TCK’nın 526. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan “kabahat” Hükümet Tasarısında suç olarak tanımlanmıştı (m. 302).

cezası olmak üzere üçe ayrılmaktaydı. 765 s. TCK'da ise, kaynak (mehaz) 1889 İtalyan CK'nda olduğu gibi, suçlar *cürüm* ve *kabahat* olarak iki grupta tasnif edilmiş olmasına rağmen, hürriyeti bağlayıcı cezalar açısından “*ağır hapis*”, “*hapis*” ve “*hafif hapis*” cezası olmak üzere üçlü ayırıma yer verilmişti. Suç oluşturan fiilin cürüm veya kabahat olarak nitelendirilmesine önemli sonuçlar bağlanmıştı⁷⁷.

Yeni TCK'da “cürüm” ve “kabahat” ayırımı terk edilerek sadece **suç** kavramına yer verildiği için, suçun karşılığında da ceza yaptırımı olarak salt **hapis cezası** öngörülmüştür.

Hapis cezası, yeni TCK'da sadece **infaz süresi** ve **infaz koşulları** bakımından, a) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, b) müebbet hapis cezası ve c) süreli hapis cezası olarak bir ayırıma tabi tutulmuştur (m. 46 – 49). Ancak, belirtmek gerekir ki, bunlar arasında, cezanın amacı veya hak yoksunluğu bakımından herhangi bir ayırım öngörülmemiştir.

Ayrıca Kanunda, somut olayda **hükmolunan hapis cezasının** süresi bakımından uzun ve **kısa süreli hapis cezası** ayırımına yer verilmiştir. Buna göre, “*Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.*” (m. 49, f. 2). Kanunda, **cezanın bireyselleştirilmesi** enstrümanı olarak, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar, ülkemiz koşulları itibarıyla uygulanabilirliği olabilecek şekilde tek tek gösterilmiştir (m. 50).

⁷⁷ Meselâ 765 s. TCK'nın sisteminde cezaların ertelenmesinde cürümlerle kabahatler açısından farklı deneme süreleri öngörülmüştü (m. 95); cürümlerle kabahatler arasında tekerrür hükümleri uygulanmamaktaydı (m. 87); cürümlere teşebbüs cezalandırılabilir iken, kabahatlere teşebbüs cezalandırılmamaktaydı (m. 61 ve 62). Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına dönüştürülmesinde bir güne tekabül eden para miktarı bakımından cürümlerle kabahatler arasında bir ayırım yapılmıştı (647 s. CİK, m. 4, f. 1). Adli sicil kaydının silinmesi açısından da cürümler ve kabahatler açısından farklı süreler öngörülmüştü (22.11.1990 t. ve 3682 s. Adli Sicil K, m. 8).

765 s. TCK'nda, suçun manevî unsuru açısından cürümlerle kabahatler arasında ilginç ayırma yer verilmişti. Buna göre, cürümler kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Eğer kanunda açıkça belirtilmiş ise, suç teşkil eden bir fiilin taksirle işlenmesi halinde dahi fail cezalandırılabilir (m. 45, f. 1). Buna karşılık, kabahatlerde ise, failin cezalandırılabilmesi için, suç teşkil eden fiilin gerçekleşmiş olması yeterli sayılmıştır. Kabahat türünden bir suçun işlenmesi açısından failin kasten mi yoksa taksirle mi hareket ettiğinin araştırılmasına gerek olmayacaktı (m. 45, f. 2). Objektif sorumluluk rejiminin benimsendiği 19. yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir ürünü olan bu düzenlemenin doğru olmadığını ifade etmek gerekir. Aslında bu düzenleme, kabahat türünden bir suç işleyen kişi aleyhine olan bir sonuç ortaya çıkarmaktaydı. Şöyle ki, meselâ bir başkasının malvarlığına taksirle zarar verilmiş olması durumunda kişi cezalandırılmayacaktır. Çünkü, başkasının malvarlığına zarar verme (nası ızzar) suçu ancak kasten işlenebilir (m. 516). Buna karşılık, kamu makamlarından gerekli izin alınmaksızın başkasına ait binanın duvarlarına afiş yapıştırmak, yazı yazmak gibi fiiller dolayısıyla, failin cezalandırılabilmesi için kastının sabit olması gerekmekteydi (m. 536) (765 s. TCK'nın sistemindeki cürüm ve kabahat ayırımının sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Marka Hakkına Tecavüz ve Cezai Sorumluluk*, in: Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp'e Armağan, cilt III, İstanbul 2003, sh. 831 vd.; DEMİRBAŞ, Timur: *Ceza Hukuku Genel Hükmümler*, Ankara, 2002, sh. 175).

Yine, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı “**Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun**”da (**İnfaz Kanununda**), mahkum olunan hapis cezasının, belirli süreleri aşmaması ve ilave birtakım şartların mevcut olması veya yerine getirilmesi halinde, özel infaz usulüne göre infaz edilebileceği yönünde hüküm bulunmaktadır (m. 110). İnfaz Kanununun söz konusu hükmünü, **cezanın bireyselleştirilmesi** enstrümanı olarak düşünmek gerekir.

Yeni TCK’ya göre, “*süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.*” (m. 49, f. 1). Ancak, belirtmek gerekir ki, bu hükümdeki üst sınır, sadece ilgili suçtan dolayı temel cezanın üst sınırının belirtilmediği hallerde üst sınır olarak anlaşılmalıdır. Bu itibarla, 49. maddedeki üst sınır, sonuç cezanın üst sınırı olarak anlaşılmamalıdır. Nitekim, Kanuna bu konuda özel bir hüküm konulmuştur:

“*Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu (Kanunun 61.) madde(s)i hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz.*” (m. 61, f. 7),

Yeni TCK’da cezaların içtimasına ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Ceza hukukunun temel kurallarından birisi, “**kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır**” şeklinde ifade edilmektedir. Bunun istisnaları, suçların içtimai bölümünde belirlenmiştir (m. 42-44). Bu istisnalar dışında, işlenen **her bir suçla ilgili olarak** ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir. Böylece **verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır**. Ancak, yeni İnfaz Kanunumuzun sisteminde, kişi hakkında hükmolunan birden fazla hapis cezasının, sadece koşullu salıverilme bakımından göz önünde bulundurulması gerekmektedir (İnfaz K, m. 107, f. 3)⁷⁸.

VI. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar

İster suç işlemiş olsun ister işlememiş olsun, insan kişiliğinin gelişimi, ancak serbest iradeye dayalıdır. Davranışlarını serbestçe belirleyebilme yeteneği, insan kişiliğinin gelişiminin olmazsa olmaz koşulunu oluşturmaktadır. Suç işlemiş olan bir insanın dahi kişiliğini geliştirmesi için davranışlarını serbestçe belirleme hürriyetine sahip olması gerekir.

Suç işleyen kişinin mahkûm olduğu cezanın infaz edilmesiyle güdülen asıl amaç, kişiye gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla etkin bir uyarıda bulunmak ve kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlamaktır. Cezanın infazıyla mahkûm

⁷⁸ Yeni TCK’nın sisteminde sadece hapis cezasına yer verilmiş olması karşısında, yürürlükte olan diğer kanunlarda “*ağır hapis cezası*” olarak öngörülen yaptırımlar, 4.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı “**Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun**”la *hapis cezasına* dönüştürülmüştür (m. 6).

Buna karşılık diğer kanunlarda “*hafif hapis cezası*” olarak öngörülen yaptırımlar *idari para cezasına* dönüştürülmüştür. Başka bir deyişle, diğer kanunlara göre, “*hafif hapis cezası*”nı gerektiren fiiller, artık suç olmaktan çıkarılmış ve kabahate dönüştürülmüştür (5252 s. K, m. 7).

gelecekte sosyal sorumluluğa sahip olarak suçsuz bir yaşantı sürmeye yatkın duruma getirilmelidir. Ancak, bu amaç, bazı suçlular bakımından sadece bir cezaya mahkûm olmakla ve hatta, kişi ile ilgili olarak bir ceza muhakemesi başlatmakla da sağlanmış olabilir.

Cezanın “özel önleme” fonksiyonu yönünden hürriyeti bağlayıcı ceza olarak hapis cezasının etkinliği daima kuşku ile karşılanmış ve bu nedenle, mahkûmların uslandırılmasının, eğitiminin ve resosyalizasyonunun sağlanması için, salt hürriyetten yoksun bırakma ile yetinilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır⁷⁹. Hürriyetten salt yoksun bırakmanın bu amaçların gerçekleşmesi açısından elverişli olmadığı muhakkaktır.

En iyi koşullar içinde de olsa, cezaevindeki infazın oluşturduğu sosyolojik ve psikolojik şartlar, mahkûmların resosyalizasyonunu güçleştirmektedir. Bu nedenle, hürriyeti bağlayıcı cezaların infaz kurumunda çektirilmesinin sebebiyet verebileceği olumsuz etkiler, sadece infaz kurumlarının koşullarının iyileştirilmesiyle önlenemez.

Hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesinin mahkûmların uslandırılması, eğitimi ve resosyalizasyonu amacı doğrultusunda sınırlandırılması, bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır⁸⁰.

Kişinin sadece belli bir cezaya mahkûm olmasıyla cezanın uyarı fonksiyonunun gerçekleşmesi ve failin bu suçtan dolayı etkin pişmanlık duyması halinde, cezasının artık infaz kurumunda çektirilmemesi gerekir. Aksi uygulama, cezanın amacının kişiyi belli yoksunluklara maruz bırakmak, kişinin acı ve ızdırap çekmesini sağlamak olduğu şeklindeki eski anlayışın hayatîyetini devam ettirmesi anlamına gelecektir.

İşlediği suç dolayısıyla kişinin cezalandırılması kural olmakla birlikte; bazı koşulların gerçekleşmesi halinde, kişi hakkında kamu davasının açılmasından sarfınazar edilmesi, açılmış olan davanın belli bir süreye kadar bekletilmesi, dava sonucunda ceza verilmesinden ya da mahkûm olunan cezanın infazından sarfınazar edilebilmesi, ceza siyasetinin gereği olarak kabul edilmektedir. Böylece, kişinin belli bir süre zarfında, ki buna *denetim süresi* denmektedir, iyi hal göstermesi, yeni bir suç işlememesi ve kendisine yüklenen yükümlülüklerle riayet etmesi halinde; hakkında kamu davası açılmamakta, açılmış olan dava sonucunda mahkûmiyet kararı verilmemekte ya da mahkûm olduğu ceza infaz edilmemektedir. Denetim süresi içinde failin yeni bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklerle riayet etmemesi halinde; açılması ertelenmiş olan kamu davası

⁷⁹ İÇEL, Kayıhan: *Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Olan Müesseselerdeki Gelişmeler ve Türk Ceza Sisteminin Bu Yönden Değerlendirilmesi*, in: *Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Açısından TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği*, İstanbul, 1977, sh. 321.

⁸⁰ İÇEL, TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, sh. 322.

açılmakta, açılmış olan davaya devam edilmekte ve sonucunda mahkûmiyet kararı verilmekte, verilmiş olan mahkûmiyet kararı infaz edilmektedir.

Denetim süresi zarfında yeni bir suç işlemeyerek iyi hal göstermesi ve kendisine yüklenen yükümlülüklerle riayet etmesi, kişinin hukuk düzenini ihlâl etmeyeceğinin, dürüst bir hayat sürmeye alışmış olduğunun karinesi olarak kabul edilmektedir⁸¹.

Failin kişilik yapısı, yaşadığı çevre, psikik ve ahlâkî eğilimleri ile kendisini suç işlemeye sevkeden saikler itibarıyla, suç işlemeyi itiyad haline getirmemiş “**tesadüfî**” **suçlu** özelliği taşıması mümkündür. Bu kişilerin işledikleri suç dolayısıyla cezalandırılmaları ya da mahkûm oldukları cezanın infaz kurumunda çektilirilmesi toplum barışı açısından bir zaruret arzetyemeyebilir. Bu kişilerin cezaevi ortamına girmeden de toplum düzenine uygun davranmaları sağlanabilir⁸². Ancak, işaret etmek gerekir ki; bu kişilerin belli bir süre **denetime** tabi tutulması gerekmektedir. Çünkü, bu kişilerin kendi haline bırakılması, tamamen serbest bırakılması, tekrar suç işlemelerine neden olabilir. Dolayısıyla, bu denetimin, kişinin tekrar topluma kazandırılmasını, toplum düzenine intibakını sağlamaya yönelik ve bunu sağlayabilecek nitelikte olması gerekir.

Hapis cezasının sakıncalarını gidermek amacıyla ihdas edilmiş olan kurumlardan bir kısmı, kişi hakkında yürütölen soruşturma ve kovuşturma aşamasında; bir kısmı ise, kişinin mahkum olduğı hapıs cezasının infazı aşamasında uygulama kabiliyeti bulabilmektedir.

A. Cezaya Mahkumiyete Engel Olan Seçenek Kurumlar

Mevzuatımızdaki düzenlemeler itibarıyla bu kurumlar, ceza muhakemesi kronolojisi göz önünde bulundurularak, şu şekilde bir sıralamaya tabi tutulabilir:

1) Uzlaşma

Belirli suçlarla ilgili olarak, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin suçun işlenmesiyle oluşan mağduriyetin etkilerinin azaltılması veya suçtan doğan zararın mümkün olduğunca giderilmesi amacına yönelik olarak uzlaşmasını sağlayan bir müessesedir. Uzlaşmanın sağlanması halinde, duruma göre, şüpheli hakkında kovuşturmayaya yer olmadığı kararı veya kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı, sanık hakkında ise kamu davasının düşürölmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmektedir (CMK, m. 253, 254).

Uzlaşma ile ilgili olarak CMK’nın 253 ve 254. maddelerinde düzenleme yapılmıştır.

⁸¹ ÖNDER, Ayhan: *Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler (Mukayeseli Hukukta ve Hukukumuzda)*, İstanbul, 1963, sh. 5.

⁸² ÖNDER, Tecil, sh. 7.

2) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Cumhuriyet savcısı, belirli ağırlık derecesine ulaşmamış suçlarla ilgili olarak, şüpheli hakkında, belli koşulların varlığı halinde ve yine belirli koşullara riayet etmesi kaydıyla, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verebilir. Hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilen şüpheli ile ilgili olarak, belirli bir süre zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklerle uygun davranması ve yeni bir suç işlememesi halinde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmektedir (CMK, m. 171, f. 2 vd.).

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesine ilişkin hükümler, esas itibarıyla CMK, m. 171, f. 1 ilâ 5'te yer almaktadır. Ayrıca TCK'nın 191. maddesinde 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, **uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ya da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmamak suçundan** dolayı hakkında soruşturma başlatılan kişi ile ilgili olarak **kamu davasının açılmasının ertelenmesine** karar verilebilmesi bağlamında **özel hükümlere** yer verilmiştir.

3) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

I. Mahkeme, sanık hakkında yaptığı yargılama sonucunda belirli bir miktarı aşmayan cezaya hükmetmesi halinde, bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilir. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda, sanığın suçu işlediği sabit görülmüş ve bu nedenle hakkında bir cezaya hükmolunmuştur; ancak verilmiş olan mahkumiyet hükmü, kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmamaktadır. Belli koşulların varlığı halinde ve yine belirli koşullara riayet etmesi kaydıyla hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanıkla ilgili olarak, belirli bir süre zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklerle uygun davrandığı ve yeni bir suç işlemediği takdirde, kamu davasının düşürülmesine karar verilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmeden önce, sanığın kendisine yüklenen suçu işlediğinin sabit görülmesi ve işlediği suç dolayısıyla hakkında cezaya hükmolunması gerekir. Ancak, mahkeme sanık hakkında **mahkumiyet kararını kurduktan sonra** vereceği kararla, bu mahkumiyet kararının açıklanmasını geri bırakacaktır. Başka bir deyişle, mahkeme yaptığı yargılama sonucunda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğini sabit görerek hakkında belli bir cezaya hükmedecektir. Ancak **hükmün kurulmasını müteakip**, mahkeme **bunun açıklanmasının geri bırakılmasına karar** verecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde, dava **derdest** olmaya devam etmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde sanık hakkında verilmiş ve fakat henüz kesinleşmemiş bir **hüküm vardır**. Dolayısıyla, hakkında hüküm kurulmuş olan kişi, **sanık** sıfatını taşımaya devam etmektedir. Ancak, kurulan bu hüküm, sanık hakkında herhangi bir hukuki so-

nuç doğurmamaktadır, herhangi bir hak yoksunluğuna sebebiyet vermemektedir.⁸³

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi, CMK'nın 231. maddesinin beşinci ve devamı fıkralarında düzenlenmiştir.

II. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için, aşağıdaki koşulların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir:

Birinci koşul: Somut olayda sanık hakkında **iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına** hükmolunması gerekir. Somut olayda hükmolunan ceza, **sadece hapis veya adli para cezası** olabilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için **adli para cezası bakımından bir sınırlama getirilmemiştir**. Keza somut olayda, hapis cezası bakımından Kanunda öngörülen üst sınırı aşmaması koşuluyla, **hem hapis hem de adli para cezasına** hükmolunmuş olması halinde de, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Failin iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkum edilmesinin yanı sıra, bu mahkumiyet hükmünde müsadereye de hükmedilmiş olabilir. Bu durum, aşağıda açıklayacağımız üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesine engel teşkil etmektedir.

Ancak belirtelim ki, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinin 5. ve devamı fıkralarının Anayasa Mahkemesinin 1.6.2023 tarihli ve E. 2022/120, K. 2023/107 sayılı Kararı ile iptal edilmesi üzerine, 2.3.2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanunla (m. 15) yapılan yeni düzenlemede, hükmün bölünmezliği ilkesine aykırı olarak, müsadere hükmünün verilebileceği durumlarda da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesinin yolu açılmıştır.

Keza, belirtelim ki, Anayasanın 174. maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez. (CMK, m. 231, f. 14)⁸⁴.

İkinci koşul: Sanığın daha önce **kasıtlı bir suçtan** mahkûm olmamış bulunması gerekir. Bu itibarla, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyet halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine engel teşkil eden mahkumiyetin, kanımızca, kasıtlı suçtan dolayı **hapis veya adli para cezasına mahkumiyet** olması gerekir ve bunun da **kesinleşmiş** olması gerekir. Bu itibarla, daha önce işlenen kasıtlı bir suçtan dolayı sadece güvenlik tedbirine hükmedilmiş olması, bilahare işle-

⁸³ Kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olmasının hukuki sonuçlarına ilişkin, bu kararın kamu görevi üstlenme bakımından bir engel oluşturmadığı hususlarında değerlendirmeler için bkz. Anayasa Mahkemesi, 31.3.2022, BB. 2018/24012, pn. 40 ilâ 44; Anayasa Mahkemesi, 21.10.2021, BB. 2016/12847, pn. 81 ilâ 85.

⁸⁴ Bu konuda ilginç bir karar için bkz. CGK, 17.12.2013, E. 2013/14-561, K. 2013/619.

nen suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine engel teşkil etmemelidir.

Daha önce işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde, mahkum olunan cezanın türü ve miktarı ne olursa olsun, bilahare işlenen suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir.

Kasıtlı suçun ne kadar zaman önce işlenmiş olduğu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi bakımından bir önem taşımamaktadır.

Bu itibarla, kasıtlı suçtan dolayı verilmiş önceki mahkumiyet, tekerrür hükümlerinin uygulanmasını gerektirmese bile, örneğin TCK'nın 58. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreler geçmiş olsa bile, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine engel teşkil edecektir.

Önceki mahkumiyetin sebebini oluşturan kasıtlı suç, örneğin kişinin henüz onsekiz yaşını ikmal etmeden önce işlediği bir suç olabilir. Bu suçtan mahkumiyet, her ne kadar bilahare işlenen suç bakımından tekerrür hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez ve bu mahkumiyete bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğmaz ise de, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine engel teşkil edecektir⁸⁵.

Daha önce işlenmiş olan suçtan dolayı mahkum olunan ceza 765 s. TCK ve 647 s. CİK hükümlerine istinaden ertelenmiş ise, deneme süresi iyi halli olarak geçirildikten sonra işlenen suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir. Çünkü deneme süresi iyi halli olarak geçirildiği için, önceki mahkumiyet esasen vaki olmamış sayılacaktır.

Buna karşılık, daha önce işlenmiş olan suçtan dolayı mahkum olunan ceza yeni TCK'nın 51. maddesi hükümlerine istinaden ertelenmiş ise, denetim süresi iyi halli olarak geçirilmiş olsa bile, bilahare işlenen suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı artık verilemeyecektir. Çünkü, yeni TCK'nın sisteminde denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde, ceza infaz edilmiş sayılacaktır ve bu cezaya mahkumiyete bağlanan hukuki sonuçlar etkisini devam ettirmektedirler⁸⁶.

Dikkat edilmelidir ki, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için aranan bu koşul, TCK'nın hem hapis cezasının ertelenmesine (m. 51), hem de seçenek yaptırımlara çevrilmesine (m. 50) ilişkin koşullara nazaran çok daha ağırdır ve bu müessesenin uygulama alanını oldukça daraltmaktadır.

⁸⁵ Aynı yönde görüş için bkz. ARTUÇ, Mustafa: "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", in: Terazi Aylık Hukuk Dergisi, yıl 3, sayı 21, Mayıs 2008, sh. 107 vd. (118).

⁸⁶ Benzer bir değerlendirme için bkz. ARAS, Bahattin: "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumu ve Uygulamadaki Sorunlar", in: Terazi Aylık Hukuk Dergisi, yıl 3, sayı 22, Haziran 2008, sh. 71 vd. (74).

Üçüncü koşul: Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda **kanaate varılması** halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Dördüncü koşul: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi için, suçun işlenmesi suretiyle mağdurun veya kamunun uğradığı **zararın**, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen **giderilmesi** gerekmektedir⁸⁷. Bu koşul, **iki halde** söz konusu olabilir.

Birinci halde;

- 1) Kanunda, sanığa yüklenen suç bakımından, **cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep olarak etkin pişmanlık** hükümleri öngörülmüştür. TCK'nın 168. maddesindeki etkin pişmanlık hükmü, gerek kapsam gerek sonuçları bakımından bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir.
- 2) Sanık etkin pişmanlık göstermiştir ve suçu işlemek suretiyle sebebiyet verdiği zararı tamamen karşılamıştır,
- 3) Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması sebebiyle, somut olayda sanık hakkında hükmolunan ceza, birinci koşul kapsamına girmektedir⁸⁸.

⁸⁷ "... hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarından birisi de suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesidir. Burada uğranılan zarardan kast edilen **maddi zarar** olup, manevi zarar bu kapsamda değerlendirilmemelidir.

Maddi zararın bizzat sanık tarafından yerine getirilmesi gerekmiyip, sanık adına onun bilgisi ve rızası tahtında üçüncü kişiler tarafından tazmin, aynen iade veya eski hale getirme suretiyle giderilmesi de olanaklıdır. Ancak herhangi bir zararın doğmadığı veya zarar doğurmaya elverişli olmayan suçlar yönünden bu koşul aranmayacaktır.

Zararın belirlenmesinde hâkim, ceza yargılamasında şahsi hak davasına yer verilmediği gerçeğini de göz önünde bulundurmak koşuluyla kanaat verici basit bir araştırma yapmalı, hukuk hâkimi gibi gerçek zararı tam anlamıyla tespiti çalışmamalıdır. Zira 5271 sayılı CYY'nın 231. maddesindeki düzenleme, kişinin ileride hukuk mahkemesinde şahsi hak davası açmasına ve giderilmediğini düşündüğü gerçek zararının kalan kısmına da hükmedilmesini isteme yönünden bir engel oluşturmamaktadır.

Diğer taraftan, bazı olaylarda zarar miktarının herkes tarafından kolaylıkla belirlenebilmesi olanaklı ise de, bazı olaylarda zararın tespiti teknik bilgi gerektirdiğinden, ancak konunun uzmanı bilirkişiler aracılığıyla belirlenebilmektedir. Bu gibi durumlarda zararın miktarı hâkim tarafından belirlenemiyorsa, bilirkişi incelemesi yaptırılmalı ve zararın karşılanması konusunda iradesini gösteren sanıktan belirlenen bu miktar zararı giderip gidermeyeceği açıkça sorulduktan sonra, sonucuna göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı tartışılmalıdır." CGK, **9.10.2012**, E. 2012/8-525, K. 2012/1805. Ayrıca bkz. CGK, **15.1.2013**, E. 2012/6-1303, K. 2013/10; CGK, **17.9.2013**, E. 2012/6-1489, K. 2013/363; CGK, **17.9.2013**, E. 2013/111-218, K. 2013/370; CGK, **10.12.2013**, E. 2012/9-1478, K. 2013/605; CGK, **17.2.2015**, E. 2014/7-297, K. 2015/3.

⁸⁸ "... inşaatı proje harici son kata kadar ruhsatsız olarak yaptığı eklentileri mühürlenmiş sanığın yapılan ihtarla rağmen 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri gereğince ruhsat almadığı, suça konu yerdeki müdahaleyi sonlandırarak imara uygun hale getirmediği anlaşılmaktadır. **İmar kirliliğine neden olma suçunu işleyen sanık, ruhsatsız olarak yaptığı bölümleri projeye uygun hale**

İkinci halde ise, sanığa yüklenen suç bakımından kanunda etkin pişmanlık hükmüleri öngörülmemiştir. Ancak, sanık suçu işlemek suretiyle mağdura verdiği maddi ve manevi bütün zararları karşılamıştır. Örneğin **kasten yaralama suçunda**, sanık yaraladığı kişinin mağduriyetinin etkilerini gidermek bakımından elinden geleni yapmış olabilir. Bu durumda da, sanık hakkında, birinci ikinci ve üçüncü koşulların varlığı halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir. **Görevi kötüye kullanma suçunu** da bu ikinci hal bağlamında değerlendirmek gerekir.

Dördüncü koşul bağlamında, **işlenmesi suretiyle** kişiler veya kamu bakımından **herhangi bir zararın meydana gelmediği suçlarda**, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir verilemeyeceği hususunda tereddüt oluşabilir. TCK'da tanımlanan **genel tehlike suçları** (m. 170 vd.) bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu suçlar bakımından da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmelidir.

Suçun işlenmesi suretiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi koşulunun sanık tarafından derhal yerine getirilememesi halinde; hakkında, bu **“zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.”** (CMK, m. 231, f. 9).

Bu dördüncü koşul bakımından mağdurun uğradığı zararın giderilmesi bağlamında ceza mahkemesi tarafından belirlenen edimin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ceza mahkemesi tarafından belirlenen **edimin tür veya miktarı, mağdur veya suçtan zarar görenin kabulüne bağlı değildir.** Bu bakımdan, mağdur veya suçtan zarar görenin, belirlenen edimin yerine getirilmesi halinde, uğradığı zararların bu suretle tamamen karşıladığına kani olması bir şart olarak aranmamaktadır.

Söz konusu koşul bakımından sanığın tazminle yükümlü olduğu zarar, mağdur veya suçtan zarar görenin sadece **maddi zararları** ile sınırlıdır⁸⁹. Bu bakımdan, söz konusu müessesenin işletilmesi bağlamında, mahkeme, mağdur veya suçtan zarar görenin manevi zararlarını göz önünde bulunduramaz⁹⁰.

Bunun doğal sonucu olarak, mağdur veya suçtan zarar gören, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bağlamında uğradığı maddi zararlar sanık tara-

getirerek 5237 sayılı TCK'nın 184/5. maddesindeki özel düzenlemeden yararlanma imkanı bulunduğu halde bunu yapmayarak anılan maddedeki özel düzenlemeden yararlanmamış olup, bu durumda 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinde düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarını yerine getirip getirmediğinin ayrıca değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.” CGK, 24.2.2015, E. 2014/4-567, K. 2015/11.

⁸⁹ Ancak, Artuç, makalesinde, kaynağı anlaşılamamakla birlikte, bizim bu bağlamda hem maddi hem de manevi zararların karşılanması gerektiği görüşünde olduğumuzu belirtmiştir (ARTUÇ, Terazi, Mayıs 2008, sh. 120).

⁹⁰ ARTUÇ, Terazi, Mayıs 2008, sh. 120; ARAS, Terazi, Haziran 2008, sh. 75.

findan tazmin edilmiş olsa bile, hukuk mahkemesine başvurarak, suçun işlenmesi suretiyle uğradığı maddi zararların tamamen tazmin edilmediğini iddia ederek, uğradığı maddi zararların karşılanmayan kısmının ve ayrıca uğradığı manevi zararın tazmini amacıyla, özel hukuk hükümlerine göre dava açabilir.

III. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmeden önce hüküm kurulmalıdır. Burada hükmün açıklanmasının geri bırakılması demek, kurulan hükmün gizli tutulması anlamına gelmemektedir. “**Hükmün açıklanmasının geri bırakılması**, müsadereye ilişkin hükümler hariç, **kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade**” etmektedir (CMK, m. 231, f. 5, son cümle).

Ancak, “**açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.**” (CMK, m. 231, f. 7). Aksi takdirde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesiyle güdülen amacın gerçekleştirilmesi imkanı ortadan kalkmaktadır⁹¹.

⁹¹ “... sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden ve doğurduğu sonuçlar itibarıyla karma bir özelliğe sahip bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suçun işlenmemesi ve yükümlülükler uygun davranılması halinde, geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak kamu davasının CMK’nın 223. maddesi uyarınca düşürülmesi sonucu doğurduğundan, bu niteliği itibarıyla sanık ile devlet arasındaki cezai nitelikteki ilişkiyi sona erdiren düşme nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

Koşullu bir düşme nedeni oluşturan **hükmün açıklanmasının geri bırakılması** kurumu; mahkûmiyet, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunma, zararın giderilmesi, suç niteliği ve ceza miktarı şeklinde sayılan objektif koşulların varlığı halinde mahkemece 6008 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önce resen, bu değişiklik sonrasında ise sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesi halinde diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate varıldığında öncelikle uygulanacak, koşulların bulunmadığı veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmaması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde ise diğer kişiselleştirme nedenleri değerlendirilebilecektir.

Sanık hakkında sonuç cezanın tayininden sonra hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması halinde, öncelikle yasal bir zorunluluk olarak CMK’nın 231. maddesinin 5–14. fıkralarında düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının bulunup bulunmadığı değerlendirilecek, mahkemece olumsuz sonuca ulaşıldığı takdirde cezanın kişiselleştirilmesine ilişkin TCK’nın 50 ve 51. maddeleri yönünden bir değerlendirme yapılabilecektir.

Görüldüğü gibi, sanık hakkında hükmolunan hapis cezası, henüz seçenek bir yaptırım olarak adli para cezasına veya tedbire çevrilmeden hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının değerlendirilmesi zorunlu olup, ancak bu konuda olumsuz bir kanaate ulaşıldığı takdirde uygulanabilecek bir hükme dayanılarak sonuç cezanın, hapis cezasından çevrilen adli para cezası veya tedbir olduğundan hareketle taksirli suçlarda hükmolunan iki yıldan fazla hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceğini kabul etmek olanaklı değildir.

Kaldı ki, CMK’nın 231. maddesinin 7 ve 11. fıkralarına aykırı olarak hükmolunan cezanın adli para cezasına çevrilmesi ve bilahare sonuç cezanın adli para cezası olduğundan bahisle hu-

Somut olayda sanığa yüklenen suç sabit görüldüğü için hakkında hapis veya adli para cezasına mahkumiyet yönünde hüküm kurulduktan sonra, koşullarının varlığı halinde, mahkeme bu mahkumiyet hükmü ile ilgili olarak ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verecektir.

Yukarıda da açıklandığı gibi, sanığın iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkum edilmesinin yanı sıra, bu **mahkumiyet hükmünde ayrıca güvenlik tedbirine hükmedilmiş olması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesine engel teşkil etmemektedir.** Ancak, **hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, sanık hakkında hükmolunan iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası ile ilgili olarak verilebilir.** Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma gibi (TCK, m. 53) cezaya mahkumiyete bağlı olarak hükmolunan güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını da etkileyecektir. Ancak somut olayda ceza yerine güvenlik tedbirine hükmolunması halinde, bu hükümle ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, cezaya mahkumiyet hükmünün bütünüyle ilgili olarak verilebilir. Hüküm kısımlara ayrılarak belirli bir yaptırımla bağlantılı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez. Bu nedenle, örneğin **müsadereye hükmedilmesi gereken durumlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez**⁹².

kuka aykırı bir uygulamanın sonuçlarından sanığın ikinci kez yararlandırılması da hukuken kabul edilemez.

...

Sanığın taksirle öldürme suçundan mahkûmiyetine karar verilen olayda, hükmolunan iki yıl altı ay hapis cezası, seçenek yaptırım olarak adli para cezasına çevrilmeden hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının değerlendirilmesi zorunlu olup, adli para cezasına çevrilmeden önceki sonuç ceza iki yıl altı ay hapis olarak tayin edildiğinden CMK'nın 231. maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Bu nedenle, taksirle öldürme suçundan kurulan iki yıl altı ay hapis cezasından çevrilen adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmünün, Özel Dairece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanıp uygulanmayacağına değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle bozulmasına karar verilmesi yerinde değildir.”: CGK, 25.9.2012, E. 2012/9-937, K. 2012/1782. Ayrıca bkz. CGK, 25.9.2012, E. 2012/9-7, K. 2012/1783; CGK, 9.10.2012, E. 2012/9-7, K. 2012/1783.

⁹² Anayasa Mahkemesinin 7.10.2021 tarihli ve 2018/1879 Bireysel Başvuru sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, B Antalya İli, Demre İlçesi Yavu Köyü 160 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların krokide işaretli alanın orman sınırları dışına çıkarılarak adına tesciline karar verilmesi talebiyle Demre Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açar.

Mahkeme, yargılama sürecinde düzenlenen bilirkişi raporlarını dikkate alarak, söz konusu alanın orman sınırları içinde kalan kısmıyla ilgili olarak “*davanın reddine*”, orman sınırları dışında kalan kısmıyla ilgili olarak ise “*karar verilmesine yer olmadığına*” hükmeder ve bu karar, Yargıtay’ın yaptığı temyiz incelemesi sonucunda onanarak kesinleşir.

Demre Cumhuriyet Başsavcılığı da B hakkında dava konusu alanda ev inşa etmek suretiyle ormanı işgal ettiği gerekçesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu, m. 93 uyarınca cezalandırılması ve söz konusu evin müsadere talebiyle Demre Ceza Mahkemesinde kamu davası açar.

Ceza Mahkemesi, yargılama sürecinde kendi görevlendirdiği bilirkişi heyetinin düzenlediği raporları dikkate alarak, B'nin üzerine ev inşa ettiği alanın orman sınırları içinde kaldığını ve dolayısıyla, işgal ve faydalanma suçunu işlediğini kabul eder ve hakkında 6831 sayılı Kanun, m. 93, f. 1 ve 2 uyarınca sonuç ceza olarak **10 ay hapis cezası** ile cezalandırılmasına hükmeder ve bu mahkûmiyet hükmüyle ilgili olarak **hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına** karar verir; ayrıca, söz konusu alandaki **ev ve eklentilerinin** 6831 sayılı Kanun, m. 93, f. 3 ile TCK, m. 54, f. 1 hükümlerine istinaden **müsadere**sine hükmeder. B, bu hükümlerle ilgili olarak temyiz kanun yoluna başvurur ise de, bu başvuru söz konusu kararların temyize tabi olmadığı gerekçesiyle reddedilir.

Demre Orman İşletme Şefliği, söz konusu müsadere hükmünün infazı bağlamında B'ye gönderdiği yazı ile evin İdareye teslim edilmesi talep eder. B, bunun üzerine Demre Asliye Ceza Mahkemesi, önce, müsadere kararının temyiz edilmiş olması sebebiyle infazının durdurulmasına karar verir; ancak bilahare Yargıtay tarafından temyiz talebinin reddine karar verilmiş olması nedeniyle, infazın durdurulmasına ilişkin kararını kaldırır. B, bu karara da itiraz eder; ancak bu itiraz, reddedilir.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu müsadere hükmünün infazı sürecinin başlatılmasıyla, B bakımından “*Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,*” karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin bu ihlal kararında **gerekçe** olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“... somut olay bağlamında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmekle müsadere kararının kesinleştiğinden de söz edilemez. Buna göre hükmün açıklanması veya davanın düşürülmesi hâlinde verilecek kararla birlikte müsadere kararı istinaf ve/veya temyiz yoluna tabi olabilecektir. Dolayısıyla mevcut aşama itibarıyla başvuruca ait ev ve müştemilatının kanuna aykırı olarak inşa edilmiş olduğu hususu kesinleşmemiştir. Anayasa Mahkemesinin de bireysel başvuru kapsamında bu evin hukuki durumunu tartışarak sonuca bağlama gibi bir görevi bulunmamaktadır.” (pn. 29).

“Ayrıca somut olayda mülk kavramı evin inşa edildiği alanın mülkiyetine göre değil bizatihi evin kendisi yönünden tartışılmalıdır. Ev ve müştemilatının taşınmaz üzerine inşa edilmiş olması nedeniyle 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 684. maddesi uyarınca taşınmazın mütemmim cüzü ve dolayısıyla taşınmazın malikinin mülkü hâline gelebileceği düşünülse bile Anayasa'nın 35. maddesi bağlamında mülk kavramı 4721 sayılı Kanun'daki anlamından bağımsızdır. Buna göre olayda müsadereye konu evin başvuruca tarafından inşa edildiği ve kendisine ait olduğu tartışma konusu değildir. Bu durumda söz konusu evin ekonomik değeri yönüyle başvuruca açısından mülk teşkil ettiği hususu tartışmasızdır. Dolayısıyla bu ev yönünden başvuruğunun Anayasa'nın 35. maddesi anlamında mevcut bir mülkü bulunmaktadır.” (pn. 30)

“Ölçülülük bağlamında ise herhangi bir gerekçe gösterilmeden ilk derece mahkemesince müsadereye karar verildiği, başvuruğun temyiz yoluna başvurmadığı ve **müsadere kararının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleşmesiyle birlikte yargılamanın nihai olarak sona ermesi beklenmeden infaz edildiği** tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesi bütün bu hususları gözетerek yargılamanın mevcut aşaması itibarıyla bütününe bakıldığında başvurucaya müsadere kararının keyfî veya kanuna aykırı olduğuna ya da makul biçimde uygulanmadığına yönelik itirazlarını ortaya koyabilme olanağının etkin bir şekilde tanınmadığı gerekçesiyle mülkiyet hakkının gerektirdiği güvenceler sağlanmadan müsadere kararının uygulanmasıyla başvurucaya yüklenen külfetin aşırı ve orantısız olduğu sonucuna varmıştır.” (pn. 36)

“Anayasa Mahkemesinin Süleyman Başmeyerdan kararında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kesinleşmeden müsadere hükmünün infazına girilmesinin mülkiyet hakkına etkisi incelenmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun **açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olan hükmün bir parçasını oluşturan müsadere kararının temyizen incelenebilmesinin mümkün bulunmadığını** kabul etmesinden hareket eden Anayasa Mahkemesi, esas hü-

Yine yukarıda açıklandığı gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde, dava **derdest** olmaya devam etmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde sanık hakkında verilmiş ve fakat henüz kesinleşmemiş bir **hüküm vardır**. Dolayısıyla, hakkında hüküm kurulmuş olan kişi, **sanık** sıfatını taşımaya devam etmektedir. Ancak, kurulan bu hüküm, sanık hakkında herhangi bir hukuki sonuç doğurmamaktadır, herhangi bir hak yoksunluğuna sebebiyet vermemektedir.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kapsamında, sanık hakkında, aşağıda açıklanacağı üzere, belirleyeceği bir süre zarfında uygulanmasını uygun gördüğü denetimli serbestlik tedbirine de karar verecektir.

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilir.” (CMK, m. 231, f. 12).

VI. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulur (CMK, m. 231, f. 8). Denetim süresi içinde **dava zamanaşımı durur**. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilebilir. Denetimli serbestlik tedbiri olarak mahkemece sanığın;

küm ile birlikte askıda bir karar olduğu hâlde müsadere tedbirinin, yargılamanın nihai olarak sona ermesi beklenmeden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleşmesiyle birlikte infazına girilmesi malike aşırı külfet yüklediğini belirtmiştir. Sözü edilen kararda, kanun koyucunun müsadere kararı için farklı bir usul veya kanun yolu düzenleyebileceği gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları yönünden de müsadereye ilişkin olarak farklı bir mekanizma da öngörebileceği ancak yapılan düzenlemenin ve uygulamanın Anayasa'nın 35. maddesinde öngörülen mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin gerekliliklere uygun olmasının ve bu çerçevede yeterli usul güvencelerini içermesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Kararda, kanun koyucunun her hâlde temyiz imkânı tanınması mecburi olmasa da böyle bir imkânın tanınması hâlinde hükmün askıya alınması, diğer bir deyişle müsadere hukuka uygun olup olmadığı hususunun kesinleşmesinin geriye bırakılmasının -belirli güvenceleri içermediği takdirde- müdahaleyi ölçüsüz kılacağını ifade ettiği açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi sonuç olarak mülkiyet hakkına müsadere yoluyla yapılan müdahalenin keyfi veya hukuka aykırı olup olmadığının ileri sürülebileceği bir yol olarak öngörülen temyiz yoluna başvuru imkânının askıya alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile birlikte müsadere kararının infazına girilmesinin -yol açılan belirsizlik ve yeterli güvencelerin sağlanmadığı dikkate alındığında- başvuruca şahsi olarak aşırı bir külfet yüklediği kanaatine varmıştır.” (pn. 38)

“Mevcut başvuruda Süleyman Başmeydan kararında ulaşılan sonuçtan ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmamaktadır.” (pn. 39)

“Bunun yanında müsadere kararına hükmedilmesi gereken hâllerde -temyiz yoluna başvuru imkânının askıya alındığı olgusu da gözetilerek- hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesinin uygulanmaması, dolayısıyla temyiz yolu askıya alınmayacak şekilde bir hüküm kurulması mülkiyet hakkına yönelik olarak yukarıda sözü edilen ihlalin ortaya çıkmasını engelleyebilecek bir çare niteliğindedir. Ancak somut olayda ... Ceza Mahkemesinin takdirini, mülkiyet hakkı ihlalinin ortaya çıkmasını önleyecek yönde kullanmadığı görülmektedir.” (pn. 40).

- 1) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,
- 2) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
- 3) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir.

Dikkat edilmelidir ki, sanık hakkında bütün (beş yıllık) denetim süresi boyunca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamaktadır. Denetimli serbestlik tedbiri, denetim süresi içinde mahkemenin bir yıldan fazla olmamak üzere belirleyeceği zaman zarfında uygulanabilecektir. **Mahkeme gerek görmediği takdirde, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanması yoluna gidilemez.** Bu itibarla, denetim süresi içinde sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanıp uygulanmaması hususunda, **mahkemenin takdir yetkisi** bulunmaktadır. Sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmaması, denetim süresinin işlevsiz kalmasını sonuçlamamaktadır.

Suçun işlenmesi suretiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi koşulunun sanık tarafından derhal yerine getirilememesi nedeniyle hakkında, bu zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmiş olması halinde (CMK, m. 231, f. 9), sanığın bu yükümlülüğünü muntazam bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde, mahkemece hüküm açıklanacaktır (CMK, m. 231, f. 11).

*“Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerle uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, **davanın düşmesi kararı** verilir.”* (CMK, m. 231, f. 10).

*“Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerle aykırı davranması halinde, **mahkeme hükmü açıklar.** Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı hâlinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir. Açıklanan veya yeni kurulan hükme **itiraz** edilebilir. İtiraz mercii ancak bu fıkradaki koşullarla sınırlı olarak bir değerlendirme yapabilir.”* (CMK, m. 231, f. 11).

Hükmün açıklanmasına karar verilmesi halinde, *“mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısı-*

na kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı hâlinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.” (CMK, m. 231, f. 11).

Dikkat edilmelidir ki, mahkeme, kuracağı yeni hükümde, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; açıklanması geri bırakılan önceki hükümde belirlenen cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının **infaz edilmemesine karar** verebilecektir. Bu durumda, mahkum olunan cezanın miktarında bir değişiklik yapılmamaktadır. Sadece, açıklanması geri bırakılan hükümde belirlenen cezanın bir kısmının infaz edilmesinden sarfınazar edilebilmektedir. Bu durum, sadece hükmolunan cezanın infazı bakımından bir önem taşımaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için aranan sanığın daha önce **kasıtlı bir suçtan** mahkûm olmamış bulunması koşulu, TCK’nın hem hapis cezasının ertelenmesine (m. 51), hem de seçenek yaptırımlara çevrilmesine (m. 50) ilişkin koşullara nazaran çok daha ağırdır ve bu müessesenin uygulama alanını oldukça daraltmaktadır. Bu nedenle mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında **sanığa yüklenen yükümlülükleri yerine getirememesi nedeniyle** hükmün açıklanmasına karar vermesi halinde, sanığın durumunu yeniden değerlendirir ve koşulları bulunduğu takdirde, *“hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.”* (CMK, m. 231, f. 11)⁹³.

⁹³ Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin kapsamının genişletilmesi dolayısıyla zaman bakımından uygulama bağlamında uygulamada ortaya çıkan sorunlara yönelik olarak sorulan sorulara cevaplarımızı içeren açıklamalar:

SORU 1) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, usul hukuku kurumu mu yoksa maddi ceza hukuku kurumudur?

CEVAP 1) Aşağıdaki bütün soruların cevabı, bu soru bakımından varılacak sonuçla doğrudan ilgilidir. Daha açık bir ifadeyle, bu kurumun bir usul kurumu olduğu sonucuna varıldığında, usul hukukunun zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke dolayısıyla, tamamlanmış işlemler bakımından yeni düzenlemeyi uygulama imkanı bulunmayacaktır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının maddi ceza hukuku müessesesi mi yoksa usul hukuku müessesesi mi olduğu hususunda kesin bir sonuca varmak mümkün değildir. Ancak, usul hukuku kurumu olduğu yönündeki gerekçelerin daha güçlü olduğu söylenebilir.

Kişi özgürlüğü ile ilişkisinden hareketle, bu kurumun maddi ceza hukuku yönünün de olduğu, bu nedenle maddi ceza hukukunun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümlerinin uygulanacağını söylemek doğru olmaz.

Her şeyden önce, bütün ceza muhakemesi kurum ve işlemleri kişi özgürlüğü ile bir biçimde ilgilidir. Ancak, bu konuda en tipik örnek olarak zikredilebilecek olan tutuklamanın, bir maddi ceza hukuku kurumu olmadığında kuşku yoktur.

Keza, bir müessesenin kişi özgürlüğü ile ilişkisinin olması, bu kurumla ilgili olarak sadece maddi ceza hukukunun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümlerinin uygulamasını gerekli kılmaz. Başka bir deyişle, karma nitelikli bir kurum olduğu kabul edilse bile, hem ceza hukukunun hem de usul hukukunun zaman bakımından uygulama kurallarını geçerli kıl-

manız gerekir ki, böyle bir şey mümkün değildir. Bu durumda ise, neden usul hukukunun kurallarının uygulanmadığı sorusunun cevabını vermek gerekir.

Sonuç olarak, her ne kadar bu kurumun her iki hukuk dalı ile irtibatı olsa da, muhakeme hukuku ile olan ilişkisinin daha yoğun olduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda ise, **derhal uygulama ilkesi** gereğince, **tamamlanmış işlem ve ilişkilerde, geriye dönük olarak bu hükmün uygulanması mümkün olmayacaktır**. Böylece, hiç olmazsa kesinleşmiş olan dosyalarda bu nedenle yeniden inceleme yapılması gerekmeyecektir.

SORU 2) Kesinleşmiş hükümler yeniden ele alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir mi?

CEVAP 2) Usul hukuku kurumu sayıldığında buna gerek kalmayacaktır.

Bu ihtimal, sadece, kurumun maddi ceza hukuku kurumu sayılması halinde gündeme gelebilecektir. Ancak bu durumda dahi, TCK m. 7, kesinleşmiş hükümlerde zorunlu olarak uygulanacak şekilde anlaşılmayabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını usul kurumu kabul etmediğimiz takdirde ise, sorunu belli ölçüde “erteleme” ile bağlantılı olarak değerlendirebiliriz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile şartları bakımından erteleme kurumu arasındaki benzerlik dikkate alındığında, erteleme yönündeki karar hukuka uygun bulunduğuna göre, kararı ertelemeyen mahkemenin, hükmün açıklanmasını geri bırakıp bırakmayacağı yönünde bir tartışma yapmak için dosyayı ele almasının bir anlamı olmayacaktır. Zira ertelemenin şartlarının oluşmadığını kabul eden mahkemenin, geri bırakmanın şartlarının oluştuğunu kabul edebileceğini düşünmek bir çelişkidir.

Bu durumda şu ihtimalleri göz önünde bulundurmak gerekir:

1. ihtimal: Kesinleşmiş olan mahkumiyet 765 s. TCK hükümlerine göre verilmiş bir mahkumiyet olup, hükmolunan ceza 647 s. CİK hükümlerine göre ertelenmiştir. Bu durumda henüz deneme süresi geçmemiş olsa bile, dosyanın yeniden ele alınmasına gerek bulunmamaktadır. Çünkü, **hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi, 765 s. TCK ile 647 s. CMK’da şartlı atıfet müessesesi olarak düzenlenen ertelemeye tekabül etmektedir**.

2. ihtimal: Hükmolunan ceza koşulları bulunmadığı için ertelenmemiş ve hüküm kesinleşmiştir. Bu durumda ertelemeye ilişkin koşulların somut olayda gerçekleşmediği kesin hükümle sabittir. Bu itibarla, söz konusu ihtimalde de, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin uygulama alanının genişlediğinden bahisle dosyanın yeniden ele alınmasına gerek bulunmamaktadır. Çünkü, **ertelemenin koşullarının gerçekleşmediği bir durumda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez**.

3. ihtimal: Kesinleşmiş olan mahkumiyet 5237 s. TCK hükümlerine göre verilmiş bir mahkumiyet olup, hükmolunan hapis cezası yine bu Kanun hükümlerine göre ertelenmiştir. Bu durumda, denetim süresinin geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesine ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi bakımından dosyanın yeniden ele alınması gerekmektedir. Çünkü, **5237 s. TCK’da erteleme, hapis cezasının bir infaz rejimi olarak düzenlenmiştir**.

SORU 3) Karara bağlanmış olup temyiz incelemesi için Yargıtay’da bulunan dosyalarda kararın salt bu nedenle bozulması uygun mu?

CEVAP 3) Kanaatimizce, salt bu nedenle karar bozulmamalıdır. Ancak diğer bozma sebepleri yanında bu husus da zikredilebilir.

Ayrıca, ikinci soruda erteleme bağlamında yaptığımız değerlendirme burada da geçerlidir. Ertelenmemiş bir mahkumiyette, hükmün açıklanmasının geri bırakılması için de bir sebep bulunmamaktadır. Bu nedenle, sadece ertelenmiş olan karar temyiz edildiğinde, erteleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması arasında, hangisinin daha lehe olduğu tartışması yapılabilir. Bununla ilgili değerlendirmemiz ise dördüncü soru altında ele alınmaktadır.

SORU 4) Suç tarihi eski olup, 765 sayılı TCK lehe kabul edilerek uygulama yapılmış ve sonuç ceza (para veya hapis cezası olabilir) şartları bulunduğundan 647 sayılı Kanunun

4) Adli Para Cezasına Hükmetme

Bazı suçların karşılığında kanunda seçimliik ceza olarak hapis ve adli para cezası öngörülmektedir. Mahkeme, suçu işleyen kişi hakkında hapis cezası yerine adli para cezasına hükmedebilecektir.

Bu konu, aşağıda ayrıntısıyla incelenecektir.

5) Önödeme

Belirli ağırlık derecesine ulaşmamış suçlarla ilgili olarak, duruma göre, şüpheli veya sanığın belli bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesi halinde, hakkında kamu davası açılmaz veya açılmış olan davanın düşürülmesine karar verilir (TCK, m. 75).

a) Tanımı ve Hukuki Niteliği

Önödeme, kanunlarda belli bir miktarda ceza öngörülen suçlardan birini işleyen kişinin savcı veya hakim tarafından belirlenen bir parayı belli bir süre zarfında Devlet hazinesine ödemesi durumunda, hakkında kamu davasının açılmaması, açılmış ise ortadan kaldırılması sonucunu doğuran bir kurumdur⁹⁴.

Ceza muhakemesi süreci, bir suçla ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve bu suretle adaletin gerçekleşmesi amacına matuftur⁹⁵. Ancak, "*mahkemelerin iş yükünü azaltmak*" hususundaki ihtiyaç⁹⁶, belli ağırlık derecesine ulaşmayan suçlar açısından ceza muhakemesinin bazı aşamalarından sarfınazar edilmesi gere-

6. maddesi uyarınca ertelenmişse, tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte düşünüldüğünde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi sanığın lehine mi yoksa aleyhine midir?

CEVAP 4) Usul kurumu sayıldığında böyle bir sorun gündeme gelmeyecektir. Ancak maddi ceza hukuku kurumu sayıldığında dahi, 765 ve 647 sayılı Kanunlar gereği mahkumiyet vaki olmamış sayılacağından, hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde bundan daha lehe bir durum oluşmayacaktır. Diğer hukuki sonuçlar da dikkate alındığında, eski düzenlemelere göre herhangi bir ilave yükümlülük bulunmaması, buna karşılık hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında ilave birtakım yükümlülüklerle hükmedilebilecek olması karşısında, yeni düzenlemenin daha aleyhe olduğu söylenebilir.

Ancak 5237 sayılı Kanun kapsamında erteleme kararı verilmişse, bu durumda mahkumiyet vaki olmamış sayılmayıp sadece ceza infaz edilmiş sayılacağından, cezanın ertelenmesine nazaran hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının daha lehe olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak; mahkumiyet konusu hapis cezasının, ertelenmediği için infaz kurumunda çektirilmesine başlanmış olan hükümlülerin, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin kapsamının genişletildiğinden bahisle, salıverilmesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

⁹⁴ Önödemenin tanımı için bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 1024; Yarg. İBK, 11.4.1983, 2/2 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1341).

⁹⁵ KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. bası, İstanbul 1998, no. 11-16; ÖZGENÇ, İzzet: Suç Zanlısı Kişinin Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü ve Bunun Hukuki Sonuçları, in: Hukuk Araştırmaları, cilt 9, yıl 1995, sayı 1-3, sh. 134.

⁹⁶ Yarg. İBK, 11.4.1983, 2/2 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1342).

ğini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla kabul edilen kurumlardan birini, önödeme oluşturmaktadır. Bu itibarla, önödeme, "*mahkemelere intikal eden işlerde önemli ölçüde azalma sağlayacağı ve mahkemelerin diğer işleriyle yeterli şekilde ilgilenmelerine imkan vereceği*" düşüncesiyle kabul edilmiştir⁹⁷.

Bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmiş ise kimin tarafından işlendiği, işleyen kişi veya kişilerin kusurlu olup olmadığı konusunda yapılması gereken yargılama faaliyetinden sarfınazar edilerek, elde mevcut delillere istinaden işlendiğinin kabulüyle bir parasal yaptırım uygulanmasından ibaret olan (mevzuatımıza özgü) bu kurumun hukuki niteliğini belirlemek gerekmektedir.

Bir görüşe göre, önödeme bir "*yargılamasız cezalandırma*" çeşididir⁹⁸. Önödeme önerisi üzerine, suç şüphesi altında bulunan kişinin rızasıyla ödemeyi gerçekleştirmesi durumunda, henüz soruşturma sürerken hemen infaz aşamasına geçilmektedir⁹⁹.

Bir diğer görüşe göre ise, önödeme, devletle suç şüphesi altında bulunan kişi arasında bir sulh anlaşması niteliğini taşımaktadır. Önödeme halinde, suç şüphesi altında bulunan kişi ceza muhakemesinin kendisine sağladığı güvencelerden vazgeçerek, kendisine yapılan belli bir parayı belli bir süre zarfında devlete ödeme hususundaki öneriyi kabul etmektedir. Bu kabule karşılık, hakkında başlatılmış olan soruşturma veya kovuşturmayla devam edilmemektedir¹⁰⁰.

Nihayet diğer bir görüşe göre; önödeme prosedürünün işletilmesiyle ceza hukuku kapsamında olan bir suç, somut olayda idari nitelikte bir suç haline dönüşmekte¹⁰¹ ve uygulanan yaptırım da idari nitelik taşımaktadır¹⁰². Bu anlayış, önödeme önerisinin hakim tarafından yapılması durumunda da kurumun idari niteliğini yitirmediğini kabul etmektedir¹⁰³.

Önödeme kurumunun kamu davasının açılmasını önleme veya açılmış olan davanın ortadan kaldırılması sonucunu doğurması itibarıyla, bir ceza muhakemesi

⁹⁷ 765 s. TCK'nın 119. maddesinin gerekçesi hakkında bkz. SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU I, sh. 1339.

⁹⁸ DÖNMEZER/ERMAN III, no. 2121.

⁹⁹ YURTCAN, Erdener. Ceza yargılaması Hukuku, 5. bası, İstanbul 1996, sh. 665.

¹⁰⁰ Bu görüşle ilgili bilgi için bkz. DÖNMEZER/ERMAN III, no. 2123. Bir anlaşmanın ancak eşit şartlarda bulunan kişiler arasında olabileceği, buna karşılık önödeme ilişkisinde devletle fertler arasındaki koşulların eşit olmadığı düşüncesiyle, bu görüş eleştirilmiştir: MAHMUTOĞLU, Fatih Selami. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul 1995, sh. 150.

¹⁰¹ MALKOÇ, İsmail/GÜLER, Mahmut. *Uygulamada Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu*, cilt II, Ankara, 1998, sh. 1684/1685.

¹⁰² EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 1024.

¹⁰³ Bkz. MAHMUTOĞLU, sh. 149.

kurumu olduğu da savunulmuştur¹⁰⁴. Bu bakımdan önödeme, bir *muhakeme engeli* niteliği göstermektedir¹⁰⁵.

Birbirinden farklı olan çeşitli görüşlerin işaret ettiğimiz bu yönleri, önödeme “kurumu”nun **hibrit** bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

b) Önödemenin Koşulları

1) *Önödeme Kapsamına Giren Bir Suçun İşlenmiş Olması Koşulu*

Önödeme kapsamına giren suçlar, yeni TCK’nın 75’inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenmektedir. Buna göre, “*uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan*” bir suçun işlenmiş olması gerekmektedir. Böylece, yeni TCK’da önödeme kapsamına giren suçların belirlenmesi ile ilgili olarak, 765 s. TCK’nın 119’uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü örnek alınmıştır¹⁰⁶.

Buna göre, miktarı ne olursa olsun **yalnız adli para cezasını gerektiren bütün suçlar** önödeme kapsamına girmektedir.

Yeni TCK’da gün para cezası sistemi kabul edilmiş olduğu için, bu sistemde nispi nitelikte adli para cezası düşünülmemiştir¹⁰⁷. Ancak, halen yürürlükte bu-

¹⁰⁴ Yarg. İBK, 11.4.1983, 2/2 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1342); aynı görüşte GÖKCAN, Hasan Tahsin/KAYMAZ, Seydi. Önödemeye Bağlı Suçlar, Ankara (tarih yok), sh. 31.

¹⁰⁵ ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 312.

¹⁰⁶ 1889 İtalyan Ceza Kanununun 101. maddesinde düzenlenen önödeme kurumu, 1926 yılında 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 119. madde olarak intikal etmişti. İlk şeklinde sadece kaba-hatlerden dolayı önödeme yoluna gidilebilmekteydi. 1936 yılında maddede yapılan değişiklikle Cumhuriyet savcısının yanı sıra mahkemenin de önödeme ihtarında bulunabilmesi kabul edilmişti. 5.3.1973 tarih ve 1696 sayılı Kanunla CMUK kapsamına alınan önödeme müessesesi cürümler için de uygulama kabiliyeti bulmuştu. 7.1.1981 tarih ve 2370 sayılı Kanunla tekrar TCK kapsamına alınan önödeme kurumunun uygulama alanı ve şartları genişletilmişti. Nihayet, 14.12.1988 tarih ve 3506 sayılı Kanunla kurumun uygulama alanı daha da genişletilerek, 765 s. TCK’daki son şeklini almıştı. Bu son değişiklikle hürriyeti bağlayıcı cezalar açısından da önödeme yoluna gidilebilmekteydi. Hatta, para cezasını gerektiren suçlar açısından sınırlama kaldırılmıştı (Müessesenin tarihi gelişimi hakkında bilgi için bkz. KUNTER/YENİSEY, no. 431; ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 310/311)..

¹⁰⁷ Yeni TCK’da gün para cezası sistemi kabul edildiği için, bu sistemde **nispi para cezasına yer verilmemiştir**. Aslında nispi para cezası, ondokuzuncu yüzyıl ceza kanunlarında yer alan müsadereye ilişkin hükümlerin yetersizliğini izale etmek ve özellikle kazanç müsaderesine yer verilmemesinin ortaya çıkardığı boşluğu doldurmak amacıyla kabul edilmişti.

Yeni TCK’da özellikle kazanç müsadereyi ayrıntılı bir şekilde düzenlendiğine göre, ayrıca çeşitli suç tanımları bağlamında ayrıca nispi para cezasının öngörülmesine gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, nispi para cezasının kabulü, bazı durumlarda suçun mağduru aleyhine sonuç doğurmaktadır. Örneğin 765 s. TCK’nın sisteminde dolandırıcılık suçuyla ilgili olarak nispi para cezası öngörülmüştü: Nitelikli dolandırıcılık suçunda, kişinin “*sağladığı haksız menfaatin iki misli kadar ağır para cezası*” (m. 504, f. 1). Bu düzenleme dolayısıyla, dolandırıcılık suçundan

lunan çeşitli kanunlarda yer alan suç tanımları bağlamında nispi nitelikte adli para cezasının öngörülmüş olduğunu gözönünde bulundurmak gerekir. 765 s. TCK'da nispi para cezasını gerektiren suçlarla ilgili olarak önödeme yoluna gidilemeyeceği kabul edilmişken (m. 119, f. 9); yeni TCK'da böyle bir sınırlama artık mevcut değildir.

Keza, üst sınırı altı ay veya daha az süreyle hapis cezasını gerektiren suçlar dolayısıyla önödeme yoluna gidilebilir. Önödeme yoluna gidilebilmesi için, su-

mahkum olan kişi için, mahkum edildiği nispi nitelikteki “ağır para cezası”nın ödenmesi, bu suç işlemekle mağdur ettiği kişinin mağduriyetini gidermeye nazaran önceliği haiz olmaktadır.

Fakat, yeni TCK'nın 158. maddesinin birinci fıkrasına 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla aşağıdaki şekilde bir cümle eklenmiştir:

“Ancak, (bu maddenin) (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, **adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.**”

Madde metninde yapılan bu değişikliğe ilişkin gerekçede şu açıklamaya yer verilmiştir:

“Maddenin birinci fıkrasında sayılan nitelikli dolandırıcılık hallerinden (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan suçların işlenmesi halinde verilecek hapis cezasının alt sınırının üç yıldan az olamayacağı, yine bu hallerde verilecek adli para cezasının miktarının suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacağı hükme bağlanmaktadır.

Bu değişikliğe göre, suçtan elde edilen gelir miktarının belli olması halinde de adli para cezasına hükmedilecektir. Ancak, Kanunun 52 ve 61. maddeleri hükümlerine göre hükmedilecek adli para cezasının miktarı, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır. Yapılan değişiklikle madde metnine eklenen hükme göre, suç tanımında belirlenen günün üst sınırından hesaplanan adli para cezasının miktarının, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmaması gerekmektedir. Bu itibarla, suçun işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin fazla olması halinde, madde metnindeki adli para cezasının unsurunu oluşturan gün bakımından getirilen sınırlamanın bir önemi kalmayacaktır.”

Bu hüküm, ülkemizde yaşanan banka kaynaklarının zimmete geçirilmesi olaylarıyla bağlantılı olarak madde metnine eklenmiştir. Bu değişiklik, bir davada banka kaynaklarının zimmete geçirilmesi dolayısıyla ilgililer hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan (765 s. TCK, m. 504) dolayı verilen mahkumiyet kararının yeni TCK'nın hükümlerinden etkilenmemesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Aslında yeni TCK'nın kazanç müsadereğine ilişkin hükümleri karşısında, bu maddede bir değişiklik yapılmasına gerek yoktu. Zaten bu hüküm, yeni TCK'nın yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihine kadar kanunlaşarak yürürlüğe konmadığı için; madde metninde yapılan bu değişikliğin, ilgili mahkumiyet kararı açısından bir önemi de kalmamıştır.

Yeni TCK'nın benimsediği yaptırım sisteminde **nispi para cezasına yer verilmemiş** olmasına rağmen; daha sonra çıkarılan çeşitli kanunlarda yer alan suç tanımları bağlamında nispi nitelikte para cezası hala varlığını muhafaza etmektedir. Örneğin, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı **Bankacılık Kanununda** yer alan özel nitelikteki zimmet suçunun nitelikli haliyle ilgili olarak nispi nitelikte adli para cezası öngörülmüştür:

“Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve **yirmibin güne kadar adli para cezası verilir; ancak, adli para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın üç katından az olamaz.**” (m. 160, f. 2; ayrıca bkz. f. 3).

Aslında bu düzenlemede, gün para cezası sistemiyle nispi nitelikteki para cezası sistemi bir ölçüde birbirleriyle telif edilmeye çalışılmıştır. Ancak, buna rağmen, söz konusu düzenleme, nispi nitelikteki para cezası sisteminin mahzurlarını taşımaya devam etmektedir.

çun kanuni tanımındaki hapis cezasının üst sınırının altı ayı aşmamış olması gerekir.

Somut olayda işlenen fiilin gerçekleşen unsurları itibarıyla uygun düştüğü suç tipinin önödeme kapsamına giren bir suç olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Bu bakımdan, önödeme hükümlerinin uygulanabilmesi için faile verilecek olan somut ceza dikkate alınamaz¹⁰⁸.

Suçun kanuni tanımında öngörülen ceza hem hapis hem de adli para cezası olabilir. Bu gibi durumlarda her iki ceza açısından da suçun önödeme kapsamına giren bir suç olup olmadığının araştırılması gerekmektedir (bkz. m. 75, f. 1, bent c).

Bazı suç tanımlarında ise, hapis cezası ile adli para cezası seçimlik cezalar olarak öngörülmüş olabilir. Bu durumda her iki ceza da önödeme kapsamında ise sorun yoktur. Buna karşılık, örneğin hapis cezasının üst sınırı altı aydan fazla ise, önödeme yoluna gidilemez. Burada seçimlik ceza olarak adli para cezasının öngörülmüş olması sonucu değiştirmeyecektir (bkz. m. 75, f. 4).

Yeni TCK'da 765 s. Kanuna nazaran önödemeye bir sınırlama getirilmiştir (m. 75, f. 1). Buna göre, önödeme için yukarıdan beri açıklamış bulunduğumuz şartları taşımakla birlikte, **suçun uzlaşma kapsamına girmesi halinde, önödeme yoluna gidilemeyecektir.** Uzlaşma kapsamına giren suçlar, CMK'nın 253. maddesinde belirlenmiştir.

24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunla önödeme müessesesinin uygulama alanı daha da genişletilmiştir. Söz konusu Kanunla TCK, m. 75'e altıncı fıkra olarak eklenen hükme göre;

“Bu madde hükümleri;

a) Bu Kanunda yer alan;

1. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (98'inci maddenin birinci fıkrası),

2. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (madde 171),

3. Çevrenin taksirle kirletilmesi (182'nci maddenin birinci fıkrası),

4. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (264'üncü maddenin birinci fıkrası),

5. Suçu bildirmeme (278'inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları),

suçları,

¹⁰⁸ "Önödemede bulunabilmek için eylemin bütün unsurları itibarıyla müstelzim olduğu ceza miktarının (temel cezanın) 119. maddede öngörülen sınırlar içinde kalması gerekmektedir.": CGK, 18.12.1989, 3-317/400 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1346 vd; Gökcan/Kaymaz, sh. 37).

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suç,
 c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 74'üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan suç,
 d) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan suç,
 bakımından da uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki suçların beş yıl içinde tekrar işlenmesi hâlinde fail hakkında aynı suçtan dolayı önödeme hükümleri uygulanmaz.”¹⁰⁹

Somut olayda müsadere edilecek eşyanın bulunması, önödeme hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Ancak, önödeme "kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez." (m. 75, f. 5).

Önödeme yoluna gidilebilmesi için kanımızca salt şüphe yeterli değildir. Bu itibarla, önödeme kapsamına giren suçun kişi tarafından işlendiği hususunda *yeterli şüphe sebeplerinin* bulunması gerekir. Bunun için önödeme kararından önce, suça ilişkin delillerin toplanması gerekmektedir. Kişi hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delillerin varlığı halinde önödeme yoluna gidilebilir. Aksi takdirde, yani kamu davası açmaya yetecek ölçüde delillerin bulunmaması durumunda önödeme yoluna gidilemeyip, kovuşturmayaya yer olmadığı kararı verilmelidir. Keza, kamu davası açıldıktan sonra önödeme yoluna gidilebilmesi için, yeterli delilin bulunması gerekmektedir. Bu itibarla, sanığın beraat edebileceği bir durumda önödeme yoluna gidilmeyip beraat kararı verilmelidir¹¹⁰.

Ancak, işaret etmek gerekir ki; 765 s Kanun gibi, yeni TCK'nın sistemi de, önödeme yoluna gidilebilmesi için soyut bir şüpheyi yeterli görmektedir. Buna göre, Cumhuriyet savcısı şüphelinin ifadesini almadan, mahkeme sanığı sorguya çekmeden önödeme ihtarında bulunabilmektedir.

2) Belli Bir Miktar Paranın Devlet Hazinesine Ödenmesi Koşulu

Önödeme kapsamına giren suçun cezasının hapis cezası olması durumunda; ödenmesi gereken para, "hapis cezasının **aşağı sınırının karşılığı** olarak her gün için otuz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktar"dır (m. 75, f. 1, bent b).

¹⁰⁹ Fıkranın bu son cümlesi hükmü karşısında; bu fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı kişi hakkında daha önce önödeme kararı verilmiş olup olmadığını takip edebilmek için, özel bir kayıt sistemi oluşturulmasına yönelik olarak, madde metnine **24.11.2016** tarihli ve 6763 sayılı Kanunla yeni bir fıkra eklenmiştir:

“Ödemede bulunulması üzerine verilen kovuşturmayaya yer olmadığına dair kararlar ile düşme kararları, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.” (f. 7).

¹¹⁰ GÖKCAN/KAYMAZ, sh. 35/36.

Buna göre, ödenmesi gereken paranın belirlenmesinde, hapis cezasının aşağı sınırı olarak, *bir aylık süre* (m. 49) dikkate alınacaktır.

Önödeme kapsamına giren suçun yalnız adli para cezasını gerektiren suç olması durumunda ise bakılacaktır. Suçun kanuni tanımında belirtilen "*adli para cezası maktu ise bu miktar, değilse* (yani aşağı ve yukarı sınırları gösterilmiş ise) *aşağı sınırın*"a eşit bir miktar para devlet hazinesine ödenecektir (m. 75, f. 1, bent a).

Bu hükümdeki adli para cezasının "aşağı sınırı" ibaresinden ne anlaşılması gerektiğine açıklık getirmek gerekir.

Klasik para cezası sisteminde bunun sınırını belirlemekte bir sorun bulunmamaktadır. Buna göre önödemede bulunulacak para miktarını, ilgili suç tanımında belirtilen adli para cezası miktarının alt sınırı oluşturacaktır. Buna karşılık, gün para cezası sisteminde "aşağı sınır"dan ne anlaşılmalı gerektiği hususunda tereddüt oluşabilir. Bu sistemde iki çözüm şekli düşünülebilir:

Birinci çözüm şekline göre; önödeme suretiyle ödenecek para miktarının belirlenmesinde, adli para cezasının **sadece gün unsurunun aşağı sınırı** dikkate alınır. Örneğin, yeni TCK'da, çevrenin taksirle kirlenmesi suçunun temel şekli (m. 182, f. 1, birinci cümle) ve muhafaza görevine taksirle aykırı davranışta bulunmak suçu (m. 289, f. 3) karşılığında sadece adli para cezası öngörülmüştür. Bu suç tanımlarında adli para cezasının alt ve üst sınırları gösterilmemiştir. Bu suçlarla ilgili olarak önödeme kararı verirken, adli para cezasının gün unsurunun alt sınırı (beş gün) göz önünde bulundurulur. Buna karşılık, kişinin bir gün karşılığı olarak ödeyeceği para miktarını Cumhuriyet savcısı veya hakim takdir etmesi gerekecektir. Yani, ödenecek para miktarının hesaplanmasında, bir gün karşılığı olarak ödenecek asgari para miktarı (yirmi Türk Lirası) dikkate alınmayacaktır.

İkinci çözüm şekline göre ise; önödeme suretiyle ödenecek para miktarının belirlenmesinde, adli para cezasının hem **gün unsurunun aşağı sınırı** (beş gün), hem de **bir gün karşılığı ödenecek para miktarının alt sınırı** (yirmi Türk Lirası), dikkate alınır.

Aslında bu iki farklı çözüm şekli, **gün para cezası sisteminin benimsendiği bir ceza kanununda, önödeme müessesesine yer verilmemesi gerektiğinin** açık bir kanıtını oluşturmaktadır.

Önödeme kapsamına giren suçun cezasının hem hapis cezası hem de adli para cezası olması durumunda; devlet hazinesine ödenecek para, hapis cezasıyla ilgili yukarıda yaptığımız açıklamalara uygun olarak belirlenecek miktar ile "*adli para cezasının aşağı sınırını*"n toplamından ibarettir (m. 75, f. 1, bent c).

Önödeme kapsamına giren suçun cezası hapis veya adli para cezası şeklinde seçimlik ceza olabilir. Bu durumda devlet hazinesine ödenecek para, suçun kanuni tanımındaki adli para cezası dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir (m. 75, f. 4).

Önödeme yoluna gidilmesinde ve devlet hazinesine ödenecek paranın belirlenmesinde örneğin yaş küçüklüğü gibi kusurluluğu etkileyen ve dolayısıyla cezada indirim yapılmasını gerektiren sebepler dikkate alınamaz¹¹¹. Keza, önödeme kapsamına giren suçun teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle, devlet hazinesine ödenecek paranın miktarında indirim yapılamaz¹¹².

Devlet hazinesine ödenecek paraya ayrıca soruşturma giderleri dahil edilecektir (m. 75, f. 1).

c) Önödeme Usulü ve Sonuçları

Önödeme kapsamına giren bir suçun işlendiği hususunda *yeterli delilin* bulunması durumunda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı şüpheliye bir *önödeme tebligatında* bulunur¹¹³. Önödeme tebligatında gösterilen paranın "*soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak* (tebliğden itibaren) *on gün içinde*" devlet hazinesine ödenmesi istenir (m. 75, f. 1).

765 s. Kanuna göre; "*Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebligatta, ödenecek miktar, ödeme süresi ve belli edilen miktarın bu süre içinde ödenmesi halinde kamu davasının açılmayacağı ve ödemediği takdirde açılacak kamu davası üzerine suçu sabit görüldüğü takdirde mahkemece tayin edilecek cezanın yarı nispetinde artırılarak hükmolunacağı sanığa bildirilir.*" (m. 119, f. 3).

Buna karşılık, yeni TCK'da böyle bir ihtarda bulunulmasına gerek görülmemiştir.

¹¹¹ "Müstelzim olduğu ceza itibarıyla 119. madde sınırları dışında kalan bir madde uygulanırken, (yaş-takdiri tahfil vs. gibi sebeplerle indirim yapılarak) belirlenen ceza bu kere 119. madde kapsamına giren miktara inse bile, artık 119. maddenin uygulanamayacağı tabiidir." : CGK, 18.12.1989, 3-317/400 (Gökcan/Kaymaz, sh. 59).

"Önödeme bulunulması için eylemin bütün unsurları itibarıyla müstelzim olduğu cezanın miktarının 119. maddede belirlenen sınırlar içinde kalması yeterlidir. Suçun kendisine değil, derecesine etki eden ve temel cezanın saptanmasında belirleyici durumda olan hükümler hariç, şahsa ve fiile bağlı cezayı artırıcı ya da azaltıcı nedenler önödeme dikkate alınmayacaktır. Delillerin takdiri suretiyle suça kalkışma, tahrik, takdiri indirim, tekerrür, yaş nedeniyle cezanın artırılması veya azaltılması mümkün olmadığı gibi, TCK'nın 119. maddesi uyarınca sorgusu dahi yapılmayan, şahsi halleri saptanamayan 11 yaşını doldurup 15 yaşını bitirmemiş olan sanığın ... işlediği ileri sürülen suçun fark ve mümeyyizi olup olmadığının saptanması, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olması halinde cezasından indirim yapılması, aksi takdirde önödeme ihtarında bulunulmayarak ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesi önödeme kurumunun ve yasa koyucunun ... amacına aykırıdır." CGK, 17.3.1998, 7-372/90 (Gökcan/Kaymaz, sh. 56/57).

"TCK'nın 119. maddesi uyarınca uygulanan önödeme ihtarında sanığın yaşı sebebiyle indirim yapılamayacağının gözetilmemesi yasaya aykırıdır." : 7. CD, 23.10.1997, 8178/8310 (Gökcan/Kaymaz, sh. 61).

"Önödeme ihtarı sırasında yapılan hesaplamada TCK'nın 55/3. maddesi ile cezasında indirim yapılmamasında, önödeme müessesesinin niteliği ile yasaya bir aykırılık yoktur." : 10. CD, 5.3.1996, 1320/2051 (Gökcan/Kaymaz, sh. 62).

¹¹² CGK, 17.6.1997, 3-154/164 (Gökcan/Kaymaz, sh. 57).

¹¹³ Bu tebligatın, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.

Şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca kendisine yapılan tebligattan itibaren on gün içinde devlet hazinesine önödemede bulunması durumunda¹¹⁴, hakkında kamu davası açılmayacaktır (m. 75, f. 1).

765 s. Kanuna göre; bu "*tebligata rağmen belli edilen miktarın süresinde ödenmemesi halinde kamu davası açılır ve suç sabit olduğu takdirde tayin edilecek ceza, aşağı ve yukarı haddi gösterilen hallerde yukarı haddi geçmemek üzere yarı nispetinde artırılarak hükmolunur.*" (m. 119, f. 4)¹¹⁵.

Ancak, yeni TCK'da böyle bir hükme yer verilmesine gerek görülmemiştir.

Şüpheliye yapılacak tebligatta suçun tanımlandığı kanun maddesinin, devlet hazinesine ödenmesi gereken miktarın ve soruşturma giderlerinin doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir¹¹⁶.

İster aynı ister farklı olsun kişinin önödeme kapsamına giren birden fazla suç işlemesi durumunda, Cumhuriyet savcılığınca her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı önödeme tebligatında bulunulur¹¹⁷.

Önödeme kapsamına giren bir suçtan dolayı "*özel kanun hükümleri gereğince (kamu davası açılıp) işin doğrudan doğruya mahkemeye intikal etmesi halinde*"¹¹⁸ dahi önödeme yoluna gidilebilir (m. 75, f. 2). Buna göre; hakim, sanığa isnad edilen suçun önödeme kapsamına girdiğini görmesi durumunda, 75'inci madde hükümlerine göre belirleyeceği parayı yargılama giderleriyle birlikte on gün içinde devlet hazinesine ödemesini kendisine bildirir.

Dikkat edilmelidir ki; 765 s. Kanundan farklı olarak, yeni TCK, bu bildirimin sanığın sorguya çekilmesinden önce yapılmasını emretmemektedir. Dolayısıyla,

¹¹⁴ Bu ödeme Cumhuriyet savcılığınca doldurulacak bir örnek formla mal müdürlüğüne yapılır.

¹¹⁵ Şüpheli Cumhuriyet savcılığına bu parayı ödemeyeceğini bildirmiş olsa bile, kamu davasının açılması için on günlük sürenin dolmasının beklenmesi gerekmektedir: 8. CD, 17.3.1977, 9137/2510 (YKD, Haziran 1977, sh. 886). Ayrıca bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 1026.

¹¹⁶ "Sanığa yapılacak bildirimde, ödeyeceği ceza miktarı, yargılama gideri tutarı, ödeme süresi, ... açıkça bildirilmelidir. Bu unsurların birinin eksikliği halinde yapılacak bildirim geçersiz olup, yasal bir sonuç doğurmayacaktır.": CGK, 1.11.1993, 3-266/292 (Gökcan/Kaymaz, sh. 58). Ayrıca bkz. GÖKCAN/KAYMAZ, sh. 40, 43.

¹¹⁷ "Sanığa isnat olunan eylemlerin ayrı ayrı suç olarak mütalâa edilmesi gerektiğine göre; sanık hakkında uygulanacak maddede gösterilen para cezasının asgari haddini ödemesi için yapılacak tebligatta, sanığın eylemine temas eden her fiil için uygulanması gereken kanun maddesiyle, bu maddede yazılı para cezasının asgari haddinin ayrı ayrı gösterilmesi ve sanığa eylemine uyan kanun maddeleriyle bu maddelerde yazılı para cezalarının asgari haddini tetkik etme imkanının verilmesi gerekir.": 9. CD, 29.4.1977, 1517/1535 (Gökcan/Kaymaz, sh. 65/66). Ayrıca bkz. GÖKCAN/KAYMAZ, sh. 40.

¹¹⁸ Örneğin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre adli cezayı gerektiren suçlar dolayısıyla kolluk makamları tarafından soruşturma evrakının doğrudan mahkemeye gönderilmesi suretiyle kamu davası açılmış olmaktadır (2918 s. Kanun, m. 114, f. 3).

yeni TCK'nın sisteminde, bu bildirim, sanık sorguya çekilmeden önce yapılabilir. Birinci fıkrada "tebliğ" ibaresi kullanıldığı halde, ikinci fıkrada "bildirim" ibaresi kullanılmıştır. Buna göre, birinci fıkraya göre Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılacak olan tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Buna karşılık, mahkemece yapılacak olan bildirim usulü, bildirimin sanık sorguya çekilmeden önce veya sonra yapılmasına göre, farklı olacaktır.

Bildirimin, sanık sorguya çekilmeden önce yapılması halinde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Buna karşılık, sanık sorguya çekildikten sonraki bildirimin, duruşmada sözlü olarak yapılması mümkün hale gelmiştir.

Paranın yargılama giderleri ile birlikte on günlük süre zarfında ödenmesi durumunda, kamu davası düşer (m. 75, f. 2). Buna karşılık, ödenmemesi durumunda ise, yargılamaya devam olunacaktır¹¹⁹.

765 s. Kanuna göre, yargılama sonucunda "*suç sabit olduğu takdirde tayin edilecek ceza, aşağı ve yukarı haddi gösterilen hallerde yukarı haddi geçmemek üzere yarı nispetinde artırılarak hükmolunur.*" (m. 119, f. 4).

Ancak, yeni TCK'da böyle bir hükme yer verilmesine gerek görülmemiştir.

C. savcılığı suçu farklı bir şekilde nitelendirip iddianameyle kamu davası açtıktan sonra, mahkeme önünde suçun önödeme kapsamına giren bir suç olduğu anlaşılmış olabilir. Bu durumda nasıl hareket edileceği maddenin üçüncü fıkrasında gösterilmiştir:

"Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suçta dönüşmesi hâlinde de yukarıdaki fıkra uygulanır."

Aslında bu husus, **Yargıtay**'ın 11.4.1983 tarih ve 2/2 sayılı **İçtihadı Birleştirme Kararı** ile açıklığa kavuşturulmuştur¹²⁰. Maddenin üçüncü fıkrası hükmüyle

¹¹⁹ "Sanığın TCK'nın 119. maddesinde öngörülen on günlük süreyi geçirdikten sonra önödeme önerisini yerine getirerek gerekli para cezasını yatırdığı nazara alınarak sanığın cezasının yarı oranında artırılması gerekir.": 2. CD, 12.9.1991, 8318/9199 (Gökcan/Kaymaz, sh. 64).

¹²⁰ "İddianamede gösterilen suç vasfının duruşmada değişmiş olması sebebiyle eyleme uygun cezanın ... TCK'nın 119. maddesi kapsamı içinde kaldığının anlaşılması veya C. savcısının yasal zorunluluğa rağmen bu madde uyarınca sanığa tebligat yapmadan dava açması durumlarında mahkemenin, sanığın sorgusunun yapıp yapılmadığı koşulunu aramadan, vereceği on günlük süre içinde önödemenin yargılama giderleri ile birlikte ödenmesi üzerine kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmelidir.": Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1344, 1345. Bu kararın eleştirisi için bkz: YURTCAN, Erdener: *İçtihadı Birleştirme Kararı Dolayısıyla Önödeme Üzerine Düşünceler*, YD, cilt 10, yıl 1984, sayı 3, sh. 230 vd.; KUNTER/YENİSEY, no. 431. Ayrıca bkz. 9. CD, 24.7.1997, 3025/4657 (Gökcan/Kaymaz, sh. 61); 9. CD, 12.11.1996, 5440/6486 (Gökcan/Kaymaz, sh. 62).

söz konusu Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararındaki çözüm şekli **kanunlaştırılmış** olmaktadır.

Cumhuriyet savcısının önödeme tebliği üzerine belirlenen paranın soruşturma giderleri ile birlikte süresinde devlet hazinesine yatırılması durumunda, şüpheli hakkında kamu davası açılmayacak ve *kovuşturmaya yer olmadığı kararı* verilecektir. Sanığın, mahkeme tarafından yapılan bildirim üzerine, belirlenen parayı yargılama giderleri ile birlikte süresinde devlet hazinesine yatırması durumunda ise, *kamu davasının düşmesi yönünde karar* verilir¹²¹. Önödeme dolayısıyla verilen gerek *kovuşturmaya yer olmadığı kararı* gerek *kamu davasının düşmesi kararı*, non bis in idem açısından aynı etkiyi doğururlar. Başka bir ifadeyle, bu gibi durumlarda önödeme gerçekleştiren kişi hakkında aynı vakıa nedeniyle cezai yaptırım uygulanması sonucunu doğuran herhangi bir soruşturma ve kovuşturma işlemi yapılamaz¹²².

Ancak, işaret etmek gerekir ki; önödeme kapsamına girmeyen bir suçtan dolayı buna rağmen önödeme prosedürünün işletilmesi ve belirlenen paranın süresinde devlet hazinesine yatırılması durumunda Cumhuriyet savcılığınca verilen *kovuşturmaya yer olmadığı kararı*, non bis in idem etkisi doğurmamaktadır¹²³.

Kişinin önödemede bulunması sonucunda hakkında "*kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması*" kararının verilmesi, işlenen suç dolayısıyla "*kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez.*" (m. 75, f. 5)¹²⁴.

Önödeme yaptırımı, failin sonradan işleyeceği suçlar açısından tekrerrü esas teşkil etmez.

Düşüncemize göre, **gün para cezası sisteminin benimsendiği yeni TCK'da önödeme müessesesine yer verilmemesi gerekirdi**. Yeni TCK'ya ilişkin TBMM Adalet Alt Komisyonundaki müzakereler sırasında bu düşüncemizi ifade etmemize rağmen; uygulama alışkanlıklarımızdan vazgeçemememizin bir sonucu olarak,

¹²¹ Yargıtay, bu kararın sanık tarafından da temyiz edilebileceğini kabul etmektedir: CGK, 5.2.1990, 2-367/6 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1345/1346; Gökcan/Kaymaz, sh. 58).

¹²² «Cumhuriyet savcılarınca (765 sayılı) TCK'nın 119. maddesine göre verilen takipsizlik kararları diğer takipsizlik kararlarından kamu davasının açılması veya yargılamanın önlenmesi bakımından farklı olup, önödemeye tabi suçlarda mahkemece tebligat yapıp önödeme yapılması üzerine verilen kamu davasının ortadan kaldırılmasına dair kararlarla aynı mahiyette olup, aynı hukuki sonucu doğuran bir karar olmakta ve (1411 sayılı) CMUK'un 253/2. maddesinde sayılan ve hüküm niteliği taşıyan kararlar meyanında sayılmak zorunluluğu bulunmaktadır.»: 10. CD, 3.3.1992, 690/1776 (Gökcan/Kaymaz, sh. 63).

¹²³ CGK., 9.4.1984, 345/129 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1348).

¹²⁴ "Sanıklar hakkında bir mahkûmiyet hükmü tesis olunmadığı, önödeme nedeniyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmiş olduğu cihetle, bu suça bağlı olarak ceza mahkemelerince tazminata hükmedilemez; hak sahibinin ilgili hukuk mahkemesine müracaatta muhtariyetine karar verilmelidir.": 2. CD., 12.4.1995, 3319/4801 (Gökcan/Kaymaz, sh. 62).

önödeme kurumu yeni Kanunda muhafaza edilmiştir. Yeni CMK’da yer alan uzlaşmaya ilişkin hükümler ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemeler karşısında, önödeme kurumuna Kanunda artık yer vermemek gerektiği kanısındayız.

Kitabımızın ilk basılarında, kanunlardaki adli para cezalarının gün para cezası sistemine uyarlanması halinde, önödeme müessesesinin işlevsiz kalmaya mahkûm olacağı yönünde bir değerlendirmede bulunmuştuk. Ancak, görülmektedir ki, önödeme müessesesi yeni TCK’nın benimsediği gün para cezası sisteminde de önemli bir fonksiyon görmeye devam edecektir. Şöyle ki, yeni TCK’nın yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yürürlüğe konan diğer kanunlarda tanımlı yapılan bazı suçların karşılığında yaptırım olarak, gün para cezası sistemine uygun da olsa, sadece adli para cezasına yer verilmektedir. Keza, 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olup, yeni TCK’nın sistemine henüz uyarlanmamış kanunlardaki nispi (misli) para cezaları da önödeme kapsamına girmiş bulunmaktadır. Zira, gün para cezası sisteminde nispi para cezası olamayacağı düşüncesiyle, yeni TCK’nın 75. maddesinde, 765 s. Kanunun 119. maddesinde olduğu gibi, nispi para cezasını gerektiren suçlarla ilgili olarak önödeme hükümlerinin uygulanamayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir¹²⁵. Ayrıca, işaret etmek gerekir ki, uygulama alanının genişletilmesine yönelik olarak TCK, m. 75’te **24.11.2016** tarihli ve 6763 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, önödeme kurumunun kalıcılığını sağlama bakımından pekiştirici bir etki doğuracaktır.

B. Hapis Cezasının İnfazı Bakımından Seçenek Kurumlar: Hapis Cezasının Toplumsal Ortamda İnfazı

İlk defa suç işleyen kişi, işlediği suç sebebiyle mahkûm edildiği belirli bir süreyi aşmayan hapis cezasını, infaz kurumunda değil, mahkûmiyet hükmünde kendisine yüklenen yükümlülüğü yerine getirmesi koşuluyla, toplumsal ortamda da çekebilmelidir.

Hapis cezasının toplumsal ortamda infazına hükmedilebilmesi için, somut olayda hapis cezası olarak belirlenen **sonuç cezasının belirli bir süreyi** (örneğin üç yıl) **aşmaması** gerekir.

Hapis cezasının toplumsal ortamda infazına hükmedilebilmesi için, kişinin **ilk defa suç işlemiş** olması gerekir. Bu itibarla, söz konusu infaz yönteminin, mükerriirlerle diğer özel tehlikeli suçlular olarak itiyadî suçlular, suçu meslek edinen kişiler ve örgüt mensubu suçlular bakımından işletilmemesi gerekir.

¹²⁵ Önödeme müessesesiyle ilgili olarak yeni TCK’nın sistemine uygun açıklamalar için ayrıca bkz. KAYMAZ, Seydi/GÖKCAN, Hasan Tahsin: *Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma ve Önödeme*, Ankara, 2005, sh. 201 vd.

Ayrıca, mahkûm edildiği hapis cezasının infaz kurumunda değil de toplumsal ortamda infaz edilmesinin, kişinin ıslah olması ve işlediği suç nedeniyle pişmanlık duyması bakımından daha yararlı olacağına mahkemece kanaat getirilmiştir. Başka bir ifadeyle, hapis cezasının toplumsal ortamda infazına karar verme hususunda hükmü veren mahkemeye takdir yetkisi tanımak gerekir.

Hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında kişiye yüklenebilecek olan yükümlülükler ile bunların her birinin asgari ve azami sürelerinin kanunla belirlenmesi gerekmektedir. Kanunda, kişiye yüklenebilecek olan yükümlülüklerin türleri, ancak ana hatlarıyla ve esas itibarıyla belirlenebilir. Bu yükümlülüklerin her birinin ayrıntısıyla kanunla belirlenmesi imkânı bulunmamaktadır.

Mahkûm olduğu hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında kişiye yüklenen **yükümlülük, ceza olmadığı gibi, “tedbir” veya güvenlik tedbiri türünden yaptırım olarak da kabul edilmemelidir**¹²⁶.

Hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında kişiye yüklenebilecek **yükümlülük**lere aşağıdaki örnekler gösterilebilir.

1) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma

Kamuya yararlı bir işte çalışma olarak, kamu kurumlarının, park ve bahçelerin, ibadethanelerin, mezarlıkların bakım ve temizlik işleri, kişiye bir yükümlülük olarak yüklenebilmelidir. Bu çalışmanın bir kamu kurumunda yapılması gerekmemelidir. Bir özel okulun, bir hastanenin, bir öğrenci yurdunun, bir yaşlı bakım yurdunun bakım ve temizlik işlerinde çalıştırılmak bu kapsamda mümkün olabilmelidir.

Mahkeme, kişinin eğitim durumunu, mesleğini, tecrübelerini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, çalışacağı kamuya yararlı işin türünü belirleyebilmelidir. Eğitim durumu, mesleği ve sosyal statüsü göz önünde bulundurularak kişiye, eğitim ve öğretim faaliyetine katkıda bulunmak şeklinde bir yükümlülük de yüklenebilmelidir. Örneğin, kişiye bir yaşlı bakım yurduna giderek, yurttan barınan yaşlıların istedikleri kitaptan onların dinleyerek anlayabileceği bir tonla ve hızla okumak şeklinde bir yükümlülük yüklenebilmelidir. Hatta, bakıma muhtaç olan ve talepte bulunan yaşlılara kendi konutlarında bakım hizmeti vermek de, kişiye kamuya yararlı bir iş olarak yüklenebilmelidir.

Kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bağlamında kişi kendisine yükümlülük olarak yüklenen işi, mahiyetine göre, **bir günde asgari üç ve azami beş saat** çalışmak suretiyle yerine getirmelidir. Bir günlük çalışma süresi ve bu işin günün hangi saatlerinde yerine getirileceği, yüklenen işin mahiyetine göre, bu yükümlülüğün yerine getirilmesine nezaret eden Denetimli Serbestlik Hizmetleri yetkilileri tarafından belirlenmelidir.

¹²⁶ Bkz. MADEN, Mehmet: *Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar*, Ankara 2012, sh. 73 vd.

Kamuya yararlı bir işte çalışma, hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında kişiye yüklenebilecek bir yükümlülük olduğu için, bu yükümlülüğe hükmedebilmek için, **kişinin rızasının aranmasına gerek olmadığı** düşüncesindeyiz.

Kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğü olarak kişiye yüklenen iş, kişinin yerleşim yeri (ikametgâhı) ile bu işi yerine getireceği yer arasındaki mesafe de göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmelidir. Rızası aranmak veya barınma imkânı sağlanmak koşuluyla, kişiye yerleşim yeri dışında başka bir yerde de çalışmak suretiyle yerine getirebileceği bir yükümlülük yüklenebilmelidir.

Kamuya yararlı işte çalışma dolayısıyla kişiye herhangi bir ücret ödenmemelidir.

2) Belli Bir Eğitim Programına Katılma

Özellikle eğitim imkânından yararlanamamış, eğitimi yarıda kalmış olan genç suçluların yarım kalan eğitimlerini tamamlayabilmelerini veya bir meslek ve sanat sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam edebilmeleri için, işledikleri suç nedeniyle mahkûm oldukları hapis cezasının toplumsal ortamda infazına karar verilebilmelidir. Bu durumda kişinin katılacağı eğitim programının asgari veya azami süresinin kanunla belirlenmesine gerek olmadığını düşünmekteyiz. Kişinin kanunen görmekle yükümlü olduğu ve fakat görmediği eğitim programının, görmekte olduğu ve fakat yarım kalan eğitim programının, yeteneklerine göre alabileceği meslek ve sanat bilgisine ilişkin eğitim programının mevzuattaki süreleri dikkate alınmak suretiyle, mahkemece bu yükümlülüğün kişi bakımından **asgari süresinin** belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda denetim süresinin, kişinin tabi tutulduğu eğitim programını başarı ile tamamlaması halinde ve en geç mahkemece belirlenen asgari sürenin iki katı kadar bir sürenin geçmesiyle, sona ermesi gerektiğini düşünmekteyiz.

3) Zararın Tazmini

Kişi işlediği suç nedeniyle mahkûm olduğu hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında, bu suçu işlemek suretiyle başkalarına veya kamuya verdiği zararı tamamen tazmin etmekle yükümlü kılınabilir. Bu suretle, sadece **maddi zararların** tazminine karar verilebilmelidir. Mahkeme, işlenen suç nedeniyle oluşan maddi zarar miktarını **nispi muhakeme** yöntemi ile belirlemelidir¹²⁷. Mahke-

¹²⁷ Yargıtay Ceza Genel Kurulunun şu kararında, **nispi muhakeme** müessesesinin hukuki mahiyeti ve hangi hususlarla ilgili olarak işletilebileceği ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır (CGK, 29.05.2007, E: 2006/1-341, K. 2007/118):

“1412 sayılı CYUY’un “*Adi hukuk meselelerinde ceza mahkemelerinin yetkisi*” başlıklı 255. maddesi, “*Bir fiilin suç olup olmaması, âdi hukuka müteallik bir meselenin halline bağlı ise ceza mahkemesi bu meseleye dahi ceza işlerindeki usul ve deliller için mer’i kaidelere göre karar verir.*

Bununla beraber mahkeme, muhakemeye ara ve hukuk dâvası açılması için alâkadarlara bir mehil verebilir.

Hukuk mahkemesinden bu babda bir hükmün çıkmasını da bekleyebilir.” hükmünü taşımaktadır.

me, belirlediği zararın, sanığın ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, def'aten veya taksitler halinde ödenmesine karar verebilmelidir. Yine mahkeme, sanığın ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, taksit sayısını ve taksitle- rin ödeme takvimini belirleme hususunda takdir yetkisine sahip olmalıdır.

Kişî mahkûmiyet hükmünde belirlenen zarar miktarını def'aten veya mahkeme- ce belirlenen vadelerde tamamen ödediği takdirde, mahkûm olduğu hapis cezası infaz edilmiş sayılacaktır.

Önemle belirtmek gerekir ki, mahkemenin belirlediği maddî zarar miktarı ve belirlenen zararın def'aten veya taksitler halinde ödenmesi, taksit sayıları ve taksitlerin ödeme takvimi, suçun mağdurunun veya suçtan zarar görenin kabu- lüne bağlı olmamalıdır. Bu itibarla, suçun mağduru veya suçtan zarar gören, ceza mahkemesinin belirlemiş olduğu maddî zarar miktarının yetersiz olduğunu düşündüğü takdirde, hukuk mahkemesinde özel hukuk hükümlerine istinaden dava açarak, maddî tazminat talebinde bulunabilir. Keza, suçun mağduru veya suçtan zarar gören, suç nedeniyle uğradığı manevî zararı, hukuk mahkemesinde özel hukuk hükümlerine göre açacağı dava ile talep edebilir. Bu açıklamaları- mızdan çıkan önemli bir sonuç da şudur: Ceza mahkemesince nispi muhakeme yöntemi ile tespit edilmiş olan ve mahkûmiyet hükmünde gösterilen zararın, ilamlı icra yoluyla tazmini cihetine gidilemez.

Hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında kişiye ancak **bir yükümlü- lük** yüklenebilmelidir. Kişiye yüklenen yükümlülüğün süresi, mahkeme tarafın- dan mahkûmiyet hükmünde ayrıca belirlenmelidir. Bu süre, ilgili yükümlülükle bağlantılı olarak kanunda belirlenen azami ve asgari süre sınırları dikkate alınarak tespit edilmelidir. Bu süre, **denetim süresi** olarak telakki edilmek gerekir.

Hapis cezasının toplumsal ortamda infazı süreci, mahkûmiyet hükmünün kesin- leştiği tarihten itibaren işlemeye başlamalıdır. Bu tarih, aynı zamanda denetim süresinin başlangıcı olarak telakki edilmelidir.

Kişî, hakkında hükmolunan hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamın- da kendisine yüklenen yükümlülüklerin gereklerini denetim süresi zarfında ye-

Aynı konu, 5271 sayılı CMY'nin "Ceza mahkemelerinin ek yetkisi" başlıklı 218. maddesinde, "(1) *Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden başka bir mahkemenin görev alanına gi- ren bir sorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu Kanun hükümlerine göre karar verebilir. Ancak, bu sorunla ilgili olarak görevli mahkemede dava açılması veya açılmış davanın sonuçlanması ile ilgili olarak bekletici sorun kararı verebilir.*" şeklinde benzer olarak düzenlenmiştir.

Bu hükümlere göre, yargılamaya konu suç ile ilgili ispat sorunu yaşanan hallerde, **hukuk mahkemelerinden karar alınmasının gerekli olması durumunda**, anılan karar ya Yargıla- ma Yasasındaki kurallar çerçevesinde ceza mahkemesince bir karara bağlanacak ya da hukuk mahkemelerinde dava açtırılarak bu mahkemeden alınacak karar sonucuna göre bir sonuca ulaşılacaktır."

rine getirdiği ve yeni bir kasıtlı suç işlemediği takdirde, bu **hapis cezası infaz edilmiş sayılmalıdır**.

Ancak belirtmek gerekir ki, **bu yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir infaz olarak telakki edilmemelidir**. Bu yükümlülükler, Denetimli Serbestlik Hizmetleri yetkililerinin gözetim ve denetimi altında yerine getirilmelidir.

Hapis cezasının infazı bağlamında kendisine yüklenen yükümlülüğün gereklerine uygun davrandığı takdirde, kişi hakkında bu hapis cezasına mahkûmiyete bağlı olarak bir hak yoksunluğunun doğmaması kural olarak sağlanmalıdır. Başka bir ifadeyle, hakkında hükmolunan hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında kendisine yüklenen yükümlülüklerin gereklerine uygun davrandığı sürece, kişiyle ilgili olarak bu hapis cezasına mahkûmiyete bağlı hak yoksunluğu kural olarak doğmamalıdır. Hatta, kendisine yüklenen yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmesi dolayısıyla hapis cezası infazı edilmiş sayıldıktan sonra da, bu cezaya bağlı olarak kişi hakkında bir hak yoksunluğunun doğmaması sağlanmalıdır.

Ancak kişinin, hapis cezasına mahkûmiyetinin sebebini oluşturan suçu,

a) kanunen sahip bulunduğu belirli bir ruhsat veya ehliyetin kendisine sağladığı yetkiyi kötüye kullanmak,

b) bu ruhsat veya ehliyetin gerekli kıldığı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak,

suretiyle işlemiş olması halinde, yukarıda sözünü ettiğimiz yükümlülüklerden birini yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak mahkûm edildiği hapis cezasının toplumsal ortamda infazı sürecinde ayrıca bir **güvenlik tedbiri** olarak bu **ruhsat veya ehliyeti kullanmaktan yasaklanabilmelidir**. Bu durumda kişi, mahkûm olduğu hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında kendisine belirli bir yükümlülük yüklenmenin yanı sıra, güvenlik tedbiri olarak belirli bir ruhsat veya ehliyeti kullanmaktan yasaklanabilmektedir. İşlediği suç nedeniyle hangi ruhsat veya ehliyeti kullanmaktan yasaklandığının mahkûmiyet hükmünde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ancak kişi, işlediği suçla hiçbir ilgisi olmayan ruhsat veya ehliyeti kullanmaktan yasaklanamamalıdır. Dikkat edilmelidir ki, ruhsat veya ehliyeti kullanmaktan yasaklanma, **güvenlik tedbiri** türünden bir **yaptırımdır**. Bu yasaklamanın süresi, mahkûmiyet hükmünde kişiye yüklenen yükümlülükle ilgili olarak belirlenen denetim süresi kadar olmalıdır. Bu yasaklama ile ilgili olarak ayrı bir süre belirlenmesinin uygulamayı güçleştireceğini düşünmekteyiz.

Örneğin, trafik kazasında bir başkasının yaralanmasına sebebiyet veren kişi, bu nedenle mahkûm olduğu hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında yaralanan kişinin uğradığı maddi zararı tazmin etmekle yükümlü kılınacak ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi bağlamında mahkûmiyet hükmünde belirlenen denetim süresi zarfında güvenlik tedbiri olarak sürücü belgesini kullanmaktan yasaklanabilecektir.

Kişinin, hapis cezasına mahkûmiyetinin sebebini oluşturan suç,

- a) üstlendiği kamu görevinin veya sahip olduğu meslek ve sanatın kendisine sağladığı yetkiyi kötüye kullanmak,
- b) sahip olduğu meslek ve sanatın gerekli kıldığı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak,

suretiyle işlemiş olması halinde de, mahkûm edildiği hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında yukarıda sözünü ettiğimiz yükümlülüklerden birini yerine getirmekle yükümlü kılınmanın yanı sıra, bu hapis cezasının toplumsal ortamda infazı sürecinde bir **güvenlik tedbiri** olarak bu **kamu görevini veya meslek ve sanatı icra etmekten** yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda **yasaklanabilmelidir**.

Belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmesi koşuluyla hapis cezasının toplumsal ortamda infazı sürecinde bu yükümlülüğün yanı sıra belirli bir ruhsat veya ehliyeti kullanmaktan veya belirli bir meslek ve sanatı icra etmekten yasaklama hususunda mahkemeye takdir yetkisi tanımak gerekir.

Kişi, hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında kendisine yüklenen yükümlülüğü yerine getirme imkânından bilahare kendi kusuru olmaksızın yoksun kalabilir. Bu durumda, mahkeme, yükümlülüğün türünü veya şartlarını değiştirebilmelidir.

Kişi, denetim süresi zarfında,

- a) hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında kendisine yüklenen yükümlülüğü kendi kusuruyla yerine getirmese,
- b) belirli bir ruhsat veya ehliyeti kullanmaktan veya belirli bir meslek ve sanatı icra etmekten yasaklama tedbirinin gereklerine aykırı hareket ederse,
- c) yeni bir kasıtlı suç işlerse,

mahkeme, kişi hakkında hükmolunan **hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine karar** verebilmelidir.

Ancak bu durumda, mahkemeye, kendisine yüklenen yükümlülüğü denetim süresi zarfında kısmen de olsa yerine getirmiş olması sebebiyle, hükümlünün cezasının bir kısmının infaz edilmiş sayılmasına karar verme hususunda takdir yetkisi tanınmalıdır.

Özellikle belirtmemiz gerekir ki, bu yükümlülükler, müstakil bir ceza veya yaptırım olarak telakki edilmediği için, bunların gereklerinin yerine getirilmemesi halinde veya yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kişinin belirli bir süre hapsedilmesi gibi ilave bir yaptırıma gerek bulunmamaktadır.

Yukarıda açıkladığımız üzere, belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmesi koşuluyla, ilk defa suç işleyen kişinin işlediği suç sebebiyle mahkûm olduğu belirli bir süreyi örneğin **üç yılı** aşmayan hapis cezasının toplumsal ortamda infazı yoluna

gidilebilmelidir. Bu infaz yönteminin uygulanabilmesi için mağdurun veya suçtan zarar görenin rızasının veya muvafakatinin aranmasına gerek bulunmamalıdır.

Ancak, bu infaz yönteminin uygulama alanı, mağdurun veya suçtan zarar görenin rızasının bulunmasına bağlı olarak genişletilebilmelidir. Örneğin taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası bakımından süre sınırlaması getirilmesine gerek olmaksızın, mağdurun veya suçtan zarar görenin rızasının varlığı halinde, bu infaz yöntemi işletilebilmelidir. Keza, kasten işlenen bir suçtan dolayı somut olayda hükmolunan örneğin beş yıla kadar hapis cezaları bakımından da, rızanın varlığı halinde ve yukarıdan beri açıkladığımız sair koşullar çerçevesinde toplumsal ortamda infaz yönteminin işletilebilmesi gerektiği kanısındayız.

Hapis cezasının tamamen veya kısmen toplumsal ortamda infazını sağlamak için **mevzuatımızdaki düzenlemeler itibarıyla** kabul edilen kurumlar, kronolojik olarak, şu şekilde bir sıralamaya tabi tutulabilir:

1) *Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar:*

İşlediği suç nedeniyle kişi hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezası, belli koşulların varlığı halinde, mahkeme tarafından, “seçenek yaptırım” olarak, adli para cezasına veya “tedbir”e çevrilebilmektedir (TCK, m. 50).

2) *Hapis cezasının ertelenmesi:* İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkum olan kişinin cezasının infaz kurumunda çektirilmesi, belli koşulların varlığı halinde ve yine belirli koşullara riayet etmesi kaydıyla, hükmü veren mahkeme tarafından ertelenebilmektedir. Bu durumda, hükümlünün, belirli bir süre zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklerle uygun davrandığı ve yeni bir suç işlemediği takdirde, cezası infaz edilmiş sayılacaktır (TCK, m. 51)¹²⁸.

3) *Koşullu salıverilme:* Kişi, mahkum olduğu hapis cezasının belli bir miktarını infaz kurumunda iyi halli olarak çektikten sonra, infaz kurumundan çıkarılmakta ve cezasının kalan kısmını, kendisine yüklenen yükümlülüklerle uygun davrandığı ve yeni bir suç işlemediği takdirde, dışarıda çekmektedir.

4) *Özel infaz şekilleri:* Kısa süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olan kişiler, cezalarını, durumlarına göre, oturdukları yerde ya da sadece hafta sonları veya geceleri infaz kurumuna girmek suretiyle çekebilmektedirler.

VII. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi

TCK’nın düzenlemesine göre, mülga 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda olduğu gibi (m. 4), işlediği suç nedeniyle kişi hakkında hükmolunan kısa süreli hapis

¹²⁸ Ertelene müessesesine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “Bir Ceza İnfaz Rejimi Olarak Ertelene”, in: Anayasa Yargısı, cilt 18, Ankara 2001, sh. 19 vd.; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/ SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER: *Yaptırım Teorisi*, 3. Kitap, 2. bası, Eylül 2002, sh. 376 vd.

cezası, belli koşulların varlığı halinde, mahkeme tarafından “seçenek yaptırım” olarak, adli para cezasına veya “tedbir”lerden birine çevrilebilmektedir (m. 50).

Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırımlardan birine hükmetme, **ceza-nın bireyselleştirilmesi enstrümanlarından birini** oluşturmaktadır.

Yeni TCK’da da (m. 49, f. 2), yürürlükten kaldırılan 647 s. İnfaz Kanununda olduğu gibi (m. 3, f. 3), somut olayda “**hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.**”

Kanunun “*Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar*” başlıklı 50. maddesinin birinci fıkrasına göre, işlediği suç dolayısıyla hakkında kısa süreli hapis cezasına hükmedilen kişinin bu cezası yerine mahkeme adli para cezasına veya belli bir “tedbir”e hükmedebilecektir (*ikame sistemi*). Mahkemece hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak “tedbir”e hükmedilmesi durumunda, faile ayrıca ceza verilmeyecektir.

Bu itibarla:

a) Mahkeme, mahkumiyet hükmünde fail hakkında işlediği suç sebebiyle sonuç ceza olarak belirlediği kısa süreli hapis cezasını, seçenek yaptırım olarak adli para cezasına çevirebilecektir. Mahkeme tarafından bu durumda izlenmesi gereken yöntem şu olmalıdır:

Yeni TCK’da adli para cezasının hesaplanmasında **gün para cezası sistemi** kabul edilmiştir. Kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında, adli para cezasının unsurlarından birini oluşturan gün sayısı olarak, hükmolunan kısa süreli hapis cezasını esas almak gerekir. Ayrıca mahkeme, kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği para miktarını, yirmi Türk Lirasından az ve yüz Türk Lirasından fazla olmamak üzere, takdir edecektir. Bulunan gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen para miktarının çarpımı suretiyle, kısa süreli hapis cezası yerine hükmedilecek adli para cezası bulunur.

Ancak işaret etmek gerekir ki; “*suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.*” (m. 50, f. 2).

Ayrıca belirtmelidir ki, hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak adli para cezasına hükmedilmesi halinde, bu ceza, yürürlükten kaldırılan 647 s. İnfaz Kanununun düzenlemelerinin (m. 6) aksine, ertelenemeyecektir.

Kanımızca, suç tanımlarında esas itibarıyla hapis cezası ile adli para cezası seçimlik cezalar olarak belirlendiği için, kanunda ayrıca kısa süreli hapis cezasının “seçenek yaptırım” olarak adli para cezasına çevrilebilmesine dair düzenlemeye yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

b) Mahkeme tarafından fail hakkında hapis cezası yerine seçenek “yaptırım” olarak “*mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki*

hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine” (TCK, m. 50, f. 1, bent b) hükmolunabilir.

Özellikle belirtmemiz gerekir ki, kısa süreli hapis cezası yerine zararın tazmini-ne hükmedilmiş olması halinde, bu tazmin, bir “tedbir” olmadığı gibi, bir ceza veya sair bir yaptırım da değildir. Ceza mahkemesinin mahkumiyet hükmünde tazminat olarak tespit edilen para miktarının icra yoluyla yerine getirilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle zararın tazmininin, mülga 647 s. İnfaz Kanununda olduğu gibi, TCK’nın 50. maddesinde bir seçenek “yaptırım” olarak nitelen-dirilmesi doğru olmamıştır.

Kanaatimizce, TCK’nın 50. maddesi düzenlemesi itibarıyla, işlenen suç nedeniyle bir zararın meydana gelmiş olması halinde, kısa süreli hapis cezası yerine seçenek “yaptırım” olarak ancak **maddi zararın** tazminine hükmedilebilmelidir.

Madde metninde bu zararın def’aten veya taksitler halinde tazmin edileceğine, taksitler halinde tazminin mümkün olması halinde, taksit miktarlarının ve ödeme takviminin ne suretle belirleneceğine dair bir açıklık bulunmamaktadır.

c) Mahkeme, kısa süreli hapis cezasını, seçenek “yaptırım” olarak ayrıca, “*en az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye*” (TCK, m. 50, f. 1, bent c) çevirebilecektir.

Maddede “*bir eğitim kurumuna devam etme*”, bir “tedbir” ve dolayısıyla, bir seçenek “yaptırım” olarak kabul edilmiştir. Maddenin ifadesine göre, kısa süreli hapis cezası, “*bir eğitim kurumuna devam etmeye ... çevrilebilir.*” Kanaatimizce, eğitim kurumuna devam etme, ancak bir cezanın infazı bağlamında kişiye yüklenen bir yükümlülük olabilir. Bu yükümlülük, ne bir tedbir ne de bir yaptırımdır. Dolayısıyla bu yükümlülüğün “infaz”ından da söz edilemez.

Madde metninde bu seçenek “yaptırım”ın kimlerle ilgili olarak uygulanabileceği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Eğitim kurumuna devam etme süresinin asgari sınırının kanunla iki yıl olarak belirlenmesinin ve bu sürenin her somut olayda mahkemenin takdirine bırakılmasının gerçekçi ve doğru olmadığını düşünmekteyiz. Madde metninde eğitim kurumuna devam etme, “*bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla*” sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamanın doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bu nedenle, örneğin lise tahsiline devam eden 17 yaşındaki bir gencin, işlemiş bulunduğu suç sebebiyle mahkum olduğu kısa süreli hapis cezasının yerine seçenek “yaptırım” olarak, başlamış bulunduğu lise tahsiline devam etmesine karar verilebilmelidir. Öğrencinin lise tahsilini başarı ile tamamlayabilmesi için bir yıllık süre yeterli olabilir. Bir yılın sonunda kişinin yükseköğretim imkanından yararlanıp yararlanamayacağı hüküm sırasında henüz belli değildir.

d) Mahkeme, mahkumiyet hükmünde suç işleyen kişi ile ilgili olarak belirlediği kısa süreli hapis cezasını, seçenek yaptırım olarak, “*belirli yerlere gitmekten*

veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya” çevirebilecektir (TCK, m. 50, f. 1, bent d).

Bu düzenlemede, “belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma”, kısa süreli hapis cezasına alternatif bir yaptırım olarak, bir tedbir olarak kabul edilmiştir.

Bu suretle kişinin mahkum olduğu kısa süreli hapis cezası, bir tedbir olarak örneğin **alkol tüketiminin yapıldığı yerlere gitmekten yasaklanmaya** çevrilebilecektir. Bu tedbirin süresi, mahkum olunan hapis cezasının yarısından az ve bir katından fazla olmamak üzere mahkeme tarafından mahkumiyet hükmünde belirlenecektir. Keza, kişinin mahkum olduğu kısa süreli hapis cezası, **belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma** tedbirine çevrilebilecektir. Örneğin spor müsabakaları sırasında başkalarına şiddet kullandığı için veya hakaret ettiği için kısa süreli hapis cezasına mahkum edilen kişinin bu cezası, **spor müsabakalarına katılmaktan yasaklanma** tedbirine çevrilebilecektir. Bu tedbirin süresi de, kişinin mahkum olduğu hapis cezasının yarısından az ve bir katından fazla olmamak üzere mahkeme tarafından mahkumiyet hükmünde belirlenecektir.

e) Kısa süreli hapis cezasına mahkumiyetin sebebini oluşturan suçun bir ruhsat veya belgenin sağladığı hak ve yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle ya da bu ruhsat veya belgenin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar olarak işlenmiş olması halinde, mahkeme, kişiyi mahkum ettiği kısa süreli hapis cezasını, sahibi bulunduğu **ruhsat veya belgenin** belirli bir süre **geri alınması** tedbirine çevirebilecektir (TCK, m. 50, f. 1, bent e)¹²⁹. Örneğin, trafikte dikkatsiz ve özensiz araç kullanan kişinin bir başkasına çarparak yaralanmasına sebebiyet vermesi halinde, mahkeme, taksirle yaralama suçundan dolayı kişiyi mahkum ettiği hapis cezasını, kişinin **sürücü belgesinin** belirli bir süre **geri alınması** tedbirine çevirebilecektir. Keza, sürücü belgesi sahibi kişinin zevkini tatmin için yüksek hızda araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokması halinde, mahkeme, TCK’nın 179. maddesi hükümlerine göre kişiyi mahkum ettiği kısa süreli hapis cezasını, kişinin **sürücü belgesinin** belirli bir süre **geri alınması** tedbirine çevirebilecektir. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda kişinin sürücü belgesi iptal edilmemektedir; sadece bu belgenin belirli bir süre kullanılması yasaklanmaktadır. Bu tedbirin süresi de, kişinin mahkum olduğu hapis cezasının yarısından az ve bir katından fazla olmamak üzere mahkeme tarafından mahkumiyet hükmünde belirlenecektir.

¹²⁹ Madde gerekçesinde belirtildiği üzere, “ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması ile belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklama seçenek yaptırımlarına başvurulabilmesi, bunların sağladığı hak ve yetkilerin kötüye kullanılması veya gerektirdiği dikkat özen yükümlülüğüne aykırı davranılması koşuluna bağlanmıştır. Böylece, ancak suçun ehliyet ve ruhsatla ya da meslek ve sanatın icrasıyla bağlantılı olması hâlinde, ehliyet ve ruhsatların geri alınması ya da meslek ve sanatın yasaklanması yaptırımına hükmedilebilecektir.”: TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 454 vd.

f) Kısa süreli hapis cezasına mahkumiyetin sebebini oluşturan suçun bir *meslek ve sanatın sağladığı hak ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle* veya bu meslek ve sanatın *gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak* işlenmiş olması halinde, mahkeme, bu nedenle kişiyi mahkum ettiği hapis cezasını, kişinin bu **meslek ve sanatı** belli bir süre **icra etmekten yasaklanması** tedbirine çevirebilecektir (TCK, m. 50, f. 1, bent e).

Bu tedbirin süresi de, kişinin mahkum olduğu hapis cezasının yarısından az ve bir katından fazla olmamak üzere mahkeme tarafından mahkumiyet hükmünde belirlenecektir.

g) Nihayet, mahkeme, kişiyi mahkum ettiği kısa süreli hapis cezasını, seçenek “yaptırım” olarak, **kamuya yararlı bir işte çalışmaya** çevirebilecektir (TCK, m. 50, f. 1, bent f). TCK’nın sisteminde, mahkeme, kamuya yararlı bir işte çalışmaya kişinin ancak gönüllü olması koşuluyla hükmedebilecektir¹³⁰.

Kamuya yararlı işte çalışma süresi de, kişinin mahkum olduğu hapis cezasının yarısından az ve bir katından fazla olmamak üzere mahkeme tarafından mahkumiyet hükmünde belirlenecektir.

Ancak, kamuya yararlı iş olarak kişinin bir günde çalışabileceği asgari ve azami süreler Kanunda belirlenmiş değildir.

Kişinin belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanması, sahibi bulunduğu bir ruhsatı, izin belgesini belirli bir süre kullanmaktan yasaklanması ve sahip olduğu meslek ve sanatı icra etmekten belirli bir süre yasaklanması, birer güvenlik tedbiri olarak yaptırımdır. Ancak bu güvenlik tedbirlerinin, hapis cezasına alternatif yaptırım olarak değil, ancak hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında bir **ek yaptırım** olarak telakki edilmesi gerekirdi. Bu yaptırımlar madde metninde birer “seçenek yaptırım” olarak belirlendiği için, birine hükmedilmiş olması halinde artık diğerine hükmedilme imkanı ortadan kalkmaktadır.

Halbuki, mağdurun uğradığı zararı tazmin etmekle veya bir eğitim kurumuna devam etmekle ya da kamuya yararlı bir işte çalışmakla yükümlü kılınan kişi, aynı zamanda belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan veya sahibi bulunduğu izin belgesini belirli bir süre kullanmaktan ya da sahip olduğu meslek ve sanatı icra etmekten belirli bir süre yasaklanabilmelidir.

¹³⁰ Madde gerekçesine göre, “kısa süreli hapis cezasına mahkûm olan kişinin cezası, hâkim tarafından uygun görülmesi ve kendisinin de rızasının bulunması hâlinde kamuya yararlı bir işte çalıştırma tedbirine çevrilecektir. Hükümlünün çalışacağı kurumda kadrolu olması ve bir ücret alması da söz konusu değildir. Kısa süreli hapis cezasını gerektiren bir suçu işlemiş olan ve eğitim derecesi elverişli bulunan bir kişinin örneğin okuma yazma öğretmek bir kursta öğretici olarak görev yapmasına karar verilmesi, bu seçenek yaptırıma örnek olarak gösterilebilir. Doğal olarak, bu tedbirin uygulanma usulü ayrı bir tüzük veya yönetmelikte belirlenecektir.”: TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 454 vd.

Örneğin, alkollü olarak araç kullanan kişinin bir trafik kazasına ve bir başkasının yaralanmasına sebebiyet vermiş olması halinde, taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan (TCK, m. 89) dolayı mahkum edileceği hapis cezasının toplumsal ortamda infazı bağlamında, mağdurun uğradığı zararları tazminle yükümlü kılınmanın yanı sıra, güvenlik tedbiri olarak sürücü belgesini kullanmaktan ve alkol tüketiminin yapıldığı yerlere gitmekten yasaklanabilmelidir.

Yukarıda da açıkladığımız üzere, bir eğitim programına devam etme ve kamuya yararlı bir işte çalışma gibi yükümlülükler, yaptırım özelliği taşımamaktadır. Yaptırımın bir özelliği, onun cibrî ve zecrî oluşudur; yani kamu gücü kullanılarak, zorla yerine getirilmesidir. Bir eğitim programına devam etmek ve kamuya yararlı bir işte çalışmak gibi yükümlülüklerle ceza mahkumiyetinin kurulması veya mahkum olunan cezanın infazı bağlamında zararın tazmini, cibrîlik ve zecrîlik karakteri taşımamaktadır. Bu nedenle, belirtilen yükümlülükleri, “tedbir” veya genel bir ifadeyle yaptırım olarak tavsif etme imkanı bulunmamaktadır.

Kısa süreli hapis cezasının “yaptırım”lardan birine çevrilmesi, hükmü kuran mahkemenin **takdirinde** olan bir husustur. Mahkemenin bu konuda takdir yetkisi **iki hususa** ilişkin bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, fail hakkında belirlenen kısa süreli hapis cezasını **seçenek “yaptırım”lardan birine çevirip çevirmeye** ilişkin bulunmaktadır. Mahkeme, seçenek “yaptırım”lardan birine çevirme konusunda kanaate vardıktan sonra, ayrıca bu cezayı **maddede sayılan “seçenek yaptırım”lardan hangisine çevireceğini** takdir edecektir.

Mahkeme her iki husustaki bu takdir yetkisini, “suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere” bakarak, kullanacaktır¹³¹.

¹³¹ «Anayasanın 141 ve CMUK'un 32. maddeleri uyarınca, mahkemelerin kararlarında göstermek zorunda bulundukları gerekçe; akla ve mantığa dayanmalı, tarafları tatmin edici bulunmalı ve denetime olanak sağlayıcı nitelikte olmalıdır.

Sanığa tayin edilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilip çevrilmeyeceği hususunda karar verilirken gösterilen gerekçenin, **soruşturma aşamasında izlenen sanığın kişiliği** ile ilgili bilgi ve belgelerin yerinde değerlendirildiğini gösterir veya suçun işlenmesindeki özellikleri açıklar biçimde geçerli, yeterli ve yasal olması aranmalıdır. Yasal, yeterli ve geçerli bir gerekçeye dayanılmadan, **sanığın kişiliğini ve suçun işlenmesindeki özellikleri değerlendirmeyen bir gerekçeye dayanılarak** kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına veya maddedeki tedbirlerden birine çevrilmesine yer olmadığına karar verilmesi, Yasa koyucunun amacına uygun düşmeyeceği gibi, cezanın kişileştirilmesi ilkesine de aykırıdır ve uygulamada keyfiliğe yol açar.

Keyfiliği önlemek, tarafları tatmin etmek ve kararları aydınlatmak için sanığın kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikler değerlendirilerek 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin uygulanmasının gerekip, gerekmediği karara bağlanmalıdır.

Bu itibarla, sanığa tayin edilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza hakkında 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilirken, Yerel Mahkemece gösterilen gerekçe yasal ve yeterli bulunma»mıştır: CGK., 20.12.1993, 10-290/327 (YKD. Haziran 1994, sh. 979 vd.).

Bu takdir yetkisinin kullanılması bağlamında tartışılması gereken noktalardan biri, kişinin daha önce bir suç işlemiş olmasıdır. Madde metninde, kısa süreli hapis cezasının seçenek “yaptırım”lardan birine çevrilebilmesi için **kişinin daha önce suç işlememiş olması bir şart olarak aranmamaktadır**. Bundan çıkan sonuç, kişinin daha önce suç işlemiş olması, bilahare işlediği suçtan dolayı mahkum olduğu kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesine mutlak bir engel teşkil etmemektedir. Mahkeme, kişinin daha önce işlemiş olduğu suçu, bu suçun türünü, bu suçtan dolayı hükmolunan cezayı, bu cezanın seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş olup olmamasını, ertelenmiş olup olmamasını, “*suçlunun kişiliği*” bağlamında değerlendirecektir. Ancak belirtmemiz gerekir ki, maddenin üçüncü fıkrasındaki şu ibare, bu bağlamda izlememiz gereken yöntem bakımından bize bir ışık tutmaktadır:

“Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile, fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkra yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.”

Bu hükmün mefhumu muhalifine göre, (bu fıkra kapsamına giren) bir kişinin daha önce işlemiş bulunduğu bir suçtan dolayı **hapis cezasına mahkum edilmiş olması halinde**, bilahare işlemiş bulunduğu suçtan dolayı mahkum olduğu (bu fıkra kapsamına giren) kısa süreli hapis cezası artık seçenek “yaptırım”lardan birine çevrilemez.

Bu kuralın, üçüncü fıkra ile sınırlı olarak değil, 50. madde kapsamında seçenek yaptırımlara çevirebilme ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gerektiği düşüncesindeyiz. Başka bir ifadeyle, TCK’nın 50. maddesinin mevcut düzenlemesi itibarıyla, **kısa süreli hapis cezasının seçenek “yaptırımlar”dan birine çevrilebilmesi için, kişi daha önce bir suç işlemiş olsa bile, bu suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmemiş olması şartını aramak gerekir**. Aksi yorum, TCK’nın diğer hükümleriyle bir çelişkiye neden olacaktır. Şöyle ki, kişinin mükerrir olarak işlediği suçun kanuni tanımında hapis cezası ile adli para cezasını seçimlik cezalar olarak belirlenmiş olması halinde, artık adli para cezasına hükmedilemeyecektir (TCK, m. 58, f. 3). Bu itibarla, mükerrir kişinin bilahare işlediği bu suçtan dolayı hakkında adli para cezasına hükmedilememekle beraber, aksi yorumun kabulü halinde, mahkum olduğu kısa süreli hapis cezası, 50. maddedeki seçenek “tedbir”lerden birine çevrilebilecektir.

Kanaatimizce kısa süreli hapis cezasının seçenek “yaptırım”lardan birine çevrilebilmesi ve daha doğru bir ifadeyle, hapis cezasının toplumsal ortamda infazı yöntemi, ancak **ilk defa suç işlemiş olan kişiler bakımından** uygulanabilmelidir. Nitekim madde gerekçesinde bu müessesenin “*gördüğü eğitim, yaşadığı sosyal çevre, psişik ve ahlâkî eğilimleri itibarıyla tesadüfi suçlu özelliği taşıyan*” kişiler bakımından öngörüldüğü ifade edilmiştir¹³². Bu itibarla, mükerrirler

¹³² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 454 vd.

ile, diğer özel tehlikeli suçlular olarak itiyadi suçlular, suçu meslek edinen kişiler ve örgüt mensubu suçlular bakımından kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilebilmesinin önünü kanunla kapamak gerekir. 50. maddenin mevcut metni itibarıyla, bu suçlular bakımından seçenek “yaptırım”lara hükmedip etmeme, mahkemenin takdirinde olan bir husustur.

Açıklandığı üzere, kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına veya maddede belirtilen “tedbir”lerden birine çevrilip çevrilmemesi hususunda mahkemenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

Ancak, daha önce bir suç işlemiş olsa bile bu suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak kaydıyla, kişinin işlediği suç sebebiyle sonuç ceza olarak mahkum olduğu **otuz gün veya daha az süreli hapis cezası**, zorunlu olarak adli para cezasına veya maddede belirtilen “tedbir”lerden birine çevrilecektir (TCK, m. 50, f. 3). Bu durumda, mahkeme, “suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere” bakarak, mahkum olduğu otuz gün veya daha az süreli hapis cezasının adli para cezasına veya maddede belirtilen “tedbir”lerden birine çevrilmesinden sarfınazar edemeyecektir.

Keza, kısa süreli hapis cezasına mahkûmiyetin sebebini oluşturan suçun, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını tamamlamamış olan bir kişi (çocuk) tarafından işlenmiş olması halinde, daha önce bir suç işlemiş olsa bile bu suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak kaydıyla, mahkum olduğu kısa süreli hapis cezası, seçenek “yaptırım”lardan birine çevrilecektir (TCK, m. 50, f. 3). Dikkat edilmelidir ki, burada kişinin yaşı, hükmün kurulduğu tarih itibarıyla değil, fiilin işlendiği tarih itibarıyla göz önünde bulundurulacaktır. Bu itibarla, **hükmün kurulduğu tarihte onsekiz yaşını doldurmuş olsa bile**, fiilin işlendiği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış olan kişinin mahkum olduğu kısa süreli hapis cezası seçenek “yaptırım”lardan birine çevrilecektir^{133,134}.

¹³³ “Suç tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olan faile verilen hapis cezası miktarı itibarıyla kısa süreli olup, bu cezanın TCK’nın 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince zorunlu olarak aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilebilmesi için, failin **daha önce hapis cezası cinsinden mahkûmiyetinin bulunmaması** gerekmektedir.

Suçta sürüklenen sanık çocuğun sabıkasında yer alan **adli para cezasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve hapis cezasına seçenek yaptırımlara** ilişkin ilamların TCK’nın 50. maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına engel oluşturmayacağı konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır.”: CGK, **10.3.2015**, E. 2013/8-816, K. 2015/39.

¹³⁴ “5237 sayılı TCK’nın 50/3. maddesindeki düzenleme ile fiili işlediği tarihte 18 yaşından küçük sanıkların daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak şartıyla mahkûm olunan bir yıl veya daha az süreli hapis cezalarının, aynı maddenin 1. fıkrasındaki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunlu kılınmış ve bu husus herhangi bir takdire bağlanmamıştır. Bu nedenle maddede yazılı şartlarının oluşması halinde başka herhangi bir değerlendirme yapılmadan özgürlüğü bağlayıcı cezanın seçenek yaptırımlardan birisine dönüştürülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, **altmışbeş yaşını tamamlamış olan kişinin** mahkum edildiği kısa süreli hapis cezası, daha önce bir suç işlemiş olsa bile bu suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak kaydıyla, seçenek “yaptırım”lardan birine çevrilecektir (TCK, m. 50, f. 3). Dikkat edilmelidir ki, burada kişinin yaşı, fiilin işlendiği tarih itibarıyla değil, **hükmün kurulduğu tarih itibarıyla** göz önünde bulundurulacaktır. Bu itibarla, **fiilin işlendiği tarihte altmışbeş yaşını doldurmamış olsa bile**, hükmün kurulduğu tarihte altmışbeş yaşını doldurmuş olan kişinin mahkum olduğu kısa süreli hapis cezası seçenek “yaptırım”lardan birine çevrilecektir.

Bu üç ihtimalde, mahkemeye hapis cezasının seçenek yaptırımlardan birine **çevirip çevirmeme konusunda** takdir yetkisi tanınmamış olmakla birlikte; mahkeme yine de hapis cezasını, seçenek “yaptırım” olarak **adli para cezasına veya “tedbir”lerden hangisine çevireceğini** takdir yetkisine sahiptir.

50. maddenin düzenlemesine göre, *“taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı hâlinde, ... adli para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz.”* (f. 4).

Bu itibarla, taksirle işlenen suçtan dolayı mahkum olunan hapis cezası, uzun (bir yıldan fazla) süreli de olsa, *“diğer koşulların varlığı hâlinde”*, yani *“suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere”* bakılarak, adli para cezasına çevrilebilecektir.

Buna karşılık CMK’nın 231/7. maddesi; “Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümdede, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez” şeklinde düzenlenmiş olup, açıklanması geri bırakılan hükümdede yer alan hapis cezasının ertelenemeyeceği ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırıma çevrilemeyeceği belirtilmiştir.

... şartlı bir düşme nedeni oluşturan hükmün açıklanmasının geri bırakılması, objektif şartların (mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarı, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmama, zararın giderilmesi) varlığı halinde, ... mahkemece diğer kişiselleştirme hükümleri olan seçenek yaptırımlara çevirme ve ertelemeden önce değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan kanun koyucu, kişi hakkında kurulan hükmün hukuki sonuç doğurmamasını ifade eden hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile belirli şartların gerçekleşmesi halinde kişilerin işledikleri birtakım suçlardan dolayı adli yönden lekelenmemeleri için bir fırsat tanımak istemiştir. Kanun koyucu, 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesine 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını düzenlediği 5-14. fıkraları eklediği aşamada 5237 sayılı TCK’nın 50/3. maddesindeki yasal düzenlemeyi ve zorunlulukları bilmektedir. Buna rağmen CMK’nın 231. maddesinin 7. fıkrasındaki düzenlemeyi yapmakla, açıklanması geri bırakılan hükümlerde 5237 sayılı TCK’nın 50/3. maddesindeki yaptırıma çevirme zorunluluğunun uygulanmamasını istediği yönündeki iradesini açıkça ortaya koymuştur. Aksi görüşün kabulü, daha önce hapis cezasına mahkum olmamış çocuklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmaması suretiyle adli yönden lekelenmeme haklarının ellerinden alınması sonucunu doğurur ki, bu sonuç hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının düzenleniş amacına açıkça aykırıdır.

Bununla birlikte, şartların gerçekleşmemesi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi veya açıklanması geri bırakılan hükmün 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesinin 11. fıkrası uyarınca açıklanması sırasında 5237 sayılı TCK’nın 50/3. maddesinde yer alan seçenek yaptırımlara çevirme zorunluluğu mahkemece gözönüne alınacaktır.”; CGK, 9.6.2015, E. 2014/3-86, K. 2015/200.

TCK'nın 85. maddesine göre, taksirli bir fiille “*birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden*” olunması halinde, **onbeş yıla** kadar hapis cezasına hükümlenilecektir (f. 2). Bu cezanın bir gün karşılığı olan asgari miktardan (20 TL'den) adli para cezasına çevrilmesi halinde dahi, uygulamada hükümlüler bakımından ekonomik durumlarıyla uyumlu olmayan, ödeme imkanı olmayan miktarlarda adli para cezaları ile cezalandırıldıkları örneklerle karşılaşılmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, bu şekilde adli para cezasına hükmedilmiş olması ile, mağdurun veya suçtan zarar görenlerin zararlarının tazmini imkanı da güçleşmekte ve hatta ortadan kaldırılmaktadır. Çünkü, adli para cezasının ödenmemesi halinde kişi hapsedilebilecektir (infaz K, m. 106). Bu nedenle, mağdurun veya suçtan görenin zararını tazmine nazaran, adli para cezasının ödenmesi, kişi bakımından önceliği haiz bulunmaktadır.

Bu itibarla, hapis cezasının toplumsal ortamda infazına dair yukarıda oluşturduğumuz teorik konsept çerçevesinde, bu hükmün yeniden formüle edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

TCK'nın 50. maddesi hükümlerine göre, 647 s. mülga İnfaz Kanununda olduğu gibi (m. 4, f. 4), “*uygulamada asıl mahkûmiyet, bu (50'nci) madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir.*” (f. 5). Bu fıkra, hapis cezasının adli para cezasına veya “tedbir”lerden birine çevrilmesindeki esas amaç göz önünde tutularak, asıl mahkûmiyetin artık çevrilen adli para cezası veya “tedbir” olduğu belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre, madde gerekçesinde de ifade edildiği gibi¹³⁵ bilahare işlenen suçtan dolayı gerek hükmolunan hapis cezasının ertelenmesinde gerek tekrerrür hükümlerinin uygulanmasında, hapis cezasının değil, bunun yerine hükmedilmiş olan adli para cezasının veya “tedbir”in dikkate alınması gerekmektedir.

Ancak, kısa süreli hapis cezası yerine hükmolunan “tedbir”in gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, kısa süreli hapis cezası infaz olunur. Bunun hukuki sonucu olarak, uygulamada artık kısa süreli hapis cezası esas alınacaktır (m. 50, f. 6)¹³⁶. Başka bir deyişle, kısa süreli hapis cezasının yerine hükmolunan “ted-

¹³⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 454 vd.

¹³⁶ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun , TCK'nın 50. maddesinin altıncı fıkrası hükmünün çocuklar bakımından uygulamasını önleyen **11.2.2014** tarihli ve E. 2013/2-789, K. 2014/56 sayılı Kararı, büyük önem taşımaktadır:

TCK'nın 50. maddesinin “altıncı fıkrasında, kısa süreli hapis cezası yerine hükmolunan adli para cezasının veya tedbirin gereklerinin yerine getirilmemesinin hukukî sonuçları düzenlenmiş olup, hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkemece kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verilecek ve bu karar derhâl infaz edilecektir. Bu durumda, uygulamada asıl mahkûmiyet kısa süreli hapis cezası olacaktır. Hükmolunan seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda ise, aynı maddenin 7. fıkrası uyarınca hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilecektir.

...

... çocuk sanıklar hakkında verilen hükümlerin infazının ana amacı çocuk haklarının korunması, çocuğun gelecekte yeniden suç işlemekten uzak kalabilmesi ve böylece toplumun da yeni suçlardan korunmasının yanısıra, onun yeniden sosyalleşmesinin temini ile topluma kazandırılmasıdır. Çocuk sanık hakkında hükmolunan ve son çare olarak düşünülen hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı mümkündür, ancak bu ceza kısa süreli olup TCK'nın 50. maddesi uyarınca adli para cezasına ya da diğer seçenek yaptırımlara çevrilmişse, adli para cezasının ödenmemesi ya da seçenek yaptırımların yerine getirilmemesi halinde artık kısa süreli hapis cezasının tamamen ya da kısmen infazına karar verilemeyecektir.

Çocuk sanıklar hakkında, sadece adli para cezasının infazı açısından bir istisna getirilerek hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezaların hapse çevrilemeyeceği ancak amme alacaklarının tahsili yöntemine başvurularak tahsil edileceğinin düzenlenmiş olması ve diğer seçenek yaptırımlar yönünden böyle bir istisnaya yer verilmemesi nedeniyle TCK'nın 50. maddesinin 6. fıkrasının çocuk sanıklar hakkında da uygulanmasının mümkün olduğu ileri sürülebilir ise de; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 4/i maddesinde çocuk haklarının korunması amacıyla özgürlüğü sınırlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması ilkesine işaret edilmesine göre, tıpkı adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezanın hapse çevrilmesi yasağına benzer şekilde, diğer seçenek yaptırımların gereğini yerine getirmeyen çocuk sanık hakkında da kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verilemeyeceği ve adli para cezasına çevrilme de dahil olmak üzere diğer seçenek yaptırımlara hükmolunması seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğinin kabulü kanun koyucunun amacına daha uygun olacaktır.

...

5237 sayılı TCK'nın 50. maddesinin 6. fıkrası ile yalnızca yetişkin sanıklarla ilgili bir düzenleme öngörüldüğü ve anılan bu düzenlemenin çocuk (hükümlülerle) ilgili olarak uygulama imkanı bulunmadığından, hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezası 5237 sayılı TCK'nın 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan seçenek yaptırıma çevrilen, ancak seçenek tedbirin gereklerini yerine getirmeyen çocuk (hükümlü) hakkında, aynı maddenin 6. fıkrası uyarınca hapis cezasının tamamen ya da kısmen infazına karar verilmeyerek, adli para cezasına çevrilmede dahil olmak üzere, 50. maddenin birinci fıkrasında yer alan diğer seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmesi gerekmektedir.”

Ayrıca bkz. CGK, **10.3.2015**, E. 2013/8-816, K. 2015/39:

Çocuk “hakkında verilen hükmün infazının ana amacı çocuk haklarının korunması, çocuğun gelecekte yeniden suç işlemekten uzak kalabilmesi ve böylece toplumun da yeni suçlardan korunmasının yanı sıra, onun yeniden sosyalleşmesinin temini ile topluma kazandırılmasıdır. Çocuk hakkında hükmolunan ve son çare olarak düşünülen hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı mümkündür; ancak bu ceza kısa süreli olup TCK'nın 50. maddesi uyarınca adli para cezasına ya da diğer seçenek yaptırımlara çevrilmişse, adli para cezasının ödenmemesi ya da seçenek yaptırımların yerine getirilmemesi halinde, artık kısa süreli hapis cezasının tamamen ya da kısmen infazına karar verilemeyecektir.

Çocuk hakkında, sadece adli para cezasının infazı açısından bir istisna getirilerek hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezaların hapse çevrilemeyeceği ancak amme alacaklarının tahsili yöntemine başvurularak tahsil edileceğinin düzenlenmiş olması ve diğer seçenek yaptırımlar yönünden böyle bir istisnaya yer verilmemesi nedeniyle TCK'nın 50. maddesinin altıncı fıkrasının çocuk hükümlüler hakkında da uygulanmasının mümkün olduğu ileri sürülebilir ise de; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 4/i maddesinde çocuk haklarının korunması amacıyla özgürlüğü sınırlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması ilkesine işaret edildiğine göre, tıpkı adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezanın hapse çevrilmesi yasağına benzer şekilde, diğer seçenek yaptırımların gereğini yerine getirmeyen çocuk hükümlü hakkında da kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verilemeyeceği ve adli para cezasına çevrilme de dahil olmak üzere diğer seçenek

bir”in gereklerini yerine getirmeyen fail hakkında, hapis cezasına mahkumiyete bağlı hukuki sonuçlar doğacaktır. Örneğin bu mahkumiyet, tekerrür hükümlerinin uygulanması bakımından dikkate alınacaktır.

Buna karşılık, kısa süreli hapis cezası yerine hükmolunan adli para cezasının infazına ilişkin gereklerin yerine getirilmemesi halinde, TCK’nın 50. maddesinin altıncı fıkrasında, 26.2.2008 tarihli ve 5739 sayılı Kanunla¹³⁷ yapılan değişiklik nedeniyle artık kısa süreli hapis cezasının infazına karar verilemeyecektir. Bu durumda, İnfaz Kanununun adli para cezasının infazına ilişkin hükümlerinin (m. 106) uygulanması gerekecektir. 5739 s. Kanunla yapılan değişikliğe göre, TCK’nın 50’nci maddesi hükmüne istinaden hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, hapis cezasına mahkumiyete bağlı sonuçlar, hükümlü bakımından doğmayacaktır.

“Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, infaz hakimliğince tedbir değiştirilir.” (m. 50, f. 7). Bu itibarla, kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi durumunda, infaz hakimi seçenek yaptırım olarak birinci fıkradaki “tedbir”lerden birine hükmedemeyecektir. Söz konusu yedinci fıkra hükmüne göre, ancak seçenek yaptırım olarak hükmedilen “tedbir”in hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, birinci fıkradaki diğer bir “tedbir”e hükmedilecektir.

VIII. Hapis Cezasının Ertelenmesi

A. Ertelemenin Amacı ve Hukuki Niteliği

İster suç işlemiş olsun ister işlememiş olsun, insan kişiliğinin gelişimi, ancak serbest iradeye dayalıdır. Davranışların serbestçe belirlenebilme özgürlüğü, insan kişiliğinin gelişiminin olmazsa olmaz koşulunu oluşturmaktadır. Suç işlemiş olan bir insanın dahi kişiliğini geliştirmesi için davranışlarını serbestçe belirleme özgürlüğüne sahip olması gerekir.

Suç işleyen kişinin mahkûm olduğu cezanın infaz edilmesiyle güdülen asıl amaç kişiye gerçekleştirdiği haksızlık dolayısıyla etkin bir uyarıda bulunmak ve kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlamaktır. Cezanın infazıyla mahkûm gelecekte sosyal sorumluluğa sahip olarak suçsuz bir yaşantı sürmeye yatkın duruma getirilmelidir. Ancak, bu amaç, bazı suçlular açısından sadece bir cezaya mahkûm olmakla sağlanmış olabilir.

yaptırımlara hükmolunması seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğinin kabulü kanun koyucunun amacına daha uygun olacaktır.”

¹³⁷ RG: 1 Mart 2008/26803).

Cezanın “özel önleme” fonksiyonu yönünden hapis cezasının etkinliği daima kuşku ile karşılanmıştır.¹³⁸ Özgürlükten yoksunluğun bu amaçların gerçekleşmesi açısından elverişli olmadığı kabul edilmektedir. En iyi koşullar içinde olsa dahi, cezaevindeki infazın tabi olduğu özel sosyolojik ve psikolojik kurallar, mahkûmların resosyalizasyonunu güçleştirmektedir. Bu nedenle, özgürlüğü kısıtlayıcı cezaların zararlı etkileri, sadece infaz kurumlarının koşullarının iyileştirilmesiyle önlenemez. Hapis cezasının belirli koşullar altında infaz kurumu dışında çektirilmesi, bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır¹³⁹.

Kişinin sadece belli bir cezaya mahkûm olmasıyla cezanın uyarı fonksiyonunun gerçekleşmesi ve failin bu suçtan dolayı etkin pişmanlık duyması durumunda, artık cezaevi ortamına konmaması gerekir. Aksi uygulama, cezanın amacının kişiyi belli yoksunluklara maruz bırakmak, kişinin acı ve ızdırap çekmesini sağlamak olduğu şeklindeki eski anlayışın hayatiyetini devam ettirmesi anlamına gelecektir.

İşlediği suç dolayısıyla kişinin cezalandırılması kural olmakla birlikte; bazı koşulların gerçekleşmesi halinde, mahkûm olunan cezanın infazından sarfınazar edilebilmesi, ceza siyasetinin gereği olarak kabul edilmektedir. Böylece, kişinin belli bir süre (*denetim süresi*) zarfında iyi hal göstermesi, kendisine yüklenen yükümlülüklerin gereğini yerine getirmesi ve yeni bir suç işlememesi halinde, mahkûm olduğu hapis cezası infaz kurumu dışında çektirilmektedir.

Failin kişilik yapısı, yaşadığı çevre, psişik ve ahlâkî eğilimleri ile kendisini suç işlemeye sevkeden saikler itibarıyla, suç işlemeyi itiyad haline getirmemiş “tesadüf” suçlu özelliği taşıması mümkündür. Bu kişilerin işledikleri suç dolayısıyla cezalandırılmaları ya da mahkûm oldukları cezanın infazı toplum barışı açısından bir zaruret arzetmeyebilir. Bu kişilerin cezaevi ortamına girmeden de toplum düzenine uygun davranmaları sağlanabilir¹⁴⁰. Ancak, işaret etmek gerekir ki; bu kişilerin belli bir süre denetime tabi tutulması gerekmektedir. Çünkü, bu kişilerin kendi haline bırakılması, tamamen serbest bırakılması, tekrar suç işlemelerine neden olabilir. Dolayısıyla, bu denetimin, kişinin tekrar topluma kazandırılmasını, toplum düzenine intibakını sağlamaya yönelik ve bunu sağlayabilecek nitelikte olması gerekir¹⁴¹.

¹³⁸ İÇEL, TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, sh. 321.

¹³⁹ İÇEL, TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, sh. 322.

¹⁴⁰ ÖNDER, Tecil, sh. 7.

¹⁴¹ Erteleme, (tecil) işlediği suçtan dolayı mahkûm edilen suçluya ait cezanın infazının belirli bir süre ile geri bırakılması ve suçlu bu süre içinde yeniden bir suç işlemediği takdirde suçun ya işlenmemiş veya hükümlülüğünün gerçekleşmemiş ya da cezanın çekilmiş sayılmasıdır.

(Mülga 765 sayılı) Türk Ceza Kanunu’na göre) cezanın ertelenmesi, hükümlüye bir deneme süresi tanıyarak cezanın yerine getirilmesini bu sürenin sonuna bırakan, bu süreyi suç işlemekten geçiren hükümlünün mahkûmiyetini “vaki olmamış” sayan bir olanaktır.

...

Erteleme cezanın infazını geri bırakan kanuni bir sebep, bir bakıma ise şartlı bir af diğer yönden de şartlı bir hükümlülük niteliğindedir. Bu durumda "ertelemenin" Ceza Hukukundaki di-

Erteleme, cezanın suçlunun kişiliğine uydurulmasının, bireyselleştirilmesinin en önemli yollarından birini oluşturmaktadır¹⁴². “*Erteleme, cezanın doğrudan doğruya sanığın kişiliğine uydurulmasını öngören yargısal bir şahısileştirme kurumudur*”¹⁴³. “*Ertelemeden amaç, cezanın suç işleyene uydurulması ve ceza yerine getirilmeden iyi hal göstereceği ve bir daha suç işlemeyeceği konusundaki kaniya dayan*”^{144,145}.

Bu kurum, ülkelerin çoğunda yaş küçüğü suçlular hakkında uygulanmaktadır. Yaş büyüğü suçlular söz konusu olduğunda, para cezaları ve ayrıca belli süreyle kadar hürriyeti bağlayıcı cezalar hakkında kabul edilmektedir. Biz, burada mevzu hukukumuz açısından ertelemenin koşullarını ve sonuçlarını inceleyeceğiz.

B. Koşulları

1) Hükmolunan Cezanın Türü ve Miktarına İlişkin Koşul

Yeni TCK’nın sisteminde, erteleme açısından işlenen suç göz önünde bulundurulmamış; sadece mahkûm olunan cezanın türü ve miktarı dikkate alınmıştır¹⁴⁶.

ğer müesseselerle kıyaslanmasından onun "müstakil", "sui generis (kendine özgü)" bir yapıya sahip olduğu sonucuna varılmaktadır.”: Anayasa Mahkemesi, 18.7.2001, E. 2001/4, K. 2001/332 (RG: 27 Ekim 2001-24566).

¹⁴² ÖNDER, Tecil, sh. 6, 74; DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1656; TURHAN, Faruk: *Yeni Türk Ceza Kanununa Göre Cezaların Ertelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar*, in: Erzinan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Erzinan ÜHFD), cilt X, sayı 3-4, yıl 2006, sh. 28.

¹⁴³ Yarg. İBBGK, 7.6.1976, 3-4/3 (YKD, Ağustos 1976, sh. 1197 vd.); CGK., 31.1.1994, 5-306/10 (YKD, Ağustos 1994, sh. 1324 vd.); CGK., 12.11.1979, 8-441/485 (YKD, Ocak 1980, sh. 114 vd.).

¹⁴⁴ 8. CD., 30.1.1985, 171/288 (YKD, Temmuz 1985, sh. 1074 vd.).

¹⁴⁵ “... erteleme, mahkûm için bir hak değil, ancak pişmanlık duyguları ile bir daha suç işlemeyeceği kanaatini uyandıracak tutum ve davranışı ile hâkimden, cezasını erteleme yetkisini kullanmasını dileyebilmek olanağını vermiş bulunmaktadır. Genellikle ertelemenin hükümlü için bir hak olmayıp, cezası ertelenen kişiler için bir lütuf ve atıfet ve toplum bakımından da yararlı bir uygulama olduğu kabul edilmektedir. Ancak, cezanın ertelenmesi bir hak olmadığına ve suçun ağırlığı toplumdaki olumsuz sonuçları ile yarattığı endişe ve huzursuzlukla orantılı bulunduğu göre, suçu, cezayı ve ertelemeyi takdir ve tayin etmek yasama meclislerinin yetkilerinden olmak gerekir. Bu konulardaki hükümlerin, toplumların yapılarındaki değişikliğe göre farklı nitelik taşımaları doğal olduğu gibi, değişen koşulların gereksindirdiği yeni hükümlerin getirilmesi, suç sınırlarının genişletilmesi ve cezalarının artırılıp erteleme dışı bırakılması da doğaldır. Bu ilkeler ülkemiz için de geçerlidir. Yeter ki Anayasal hak ve özgürlüklerin özü zedelenmiş bulunmasın.

Aynı suçu işlemiş olanlardan birinin cezasının hemen çektirilmesi yanında ötekini cezasının ertelenmesi; ayrıcalık yaratacak ve Anayasa’nın 10. maddesinde yazılı hukuk devleti, sosyal adalet ilkeleriyle çelişecek bir görünümde ise de, aslında bu düzenleme sosyal adaleti gerçekleştirmek, toplumun ekonomik ve sosyal yapısını pekiştirmek amacına yöneliktir. Bugün soyut adalet görüşü yerine, sosyal adalet görüşü ağırlık kazanmıştır. Aynı suçu işlemiş olanlardan birinin cezasını çekerken diğerinin cezasının ertelenmesinin temelinde toplum yararı ve sosyal adalet düşüncesi yatmaktadır. Bu nedendir ki, erteleme, kişi için hak değildir ve toplum yararına kullanılmak üzere hâkimin takdirine bırakılmıştır.”: Anayasa Mahkemesi, 24.3.1977, E. 1977/3, K. 1977/19 (RG: 13 Haziran 1977/15965).

¹⁴⁶ Ancak, işaret etmek gerekir ki; mevzuatımızda bazı suçlarla ilgili olarak verilen cezaların ertelenemeyeceğine dair hükümler bulunmaktadır. Nitekim Kanunda “*Bazı suçlara ilişkin ce-*

Hükmolunan ceza, hapis cezası ise ertelenebilecektir. Buna karşılık, yeni TCK'nın sisteminde adli para cezasının ertelenmesi söz konusu değildir¹⁴⁷. Bu bakımdan yeni TCK, yürürlükten kaldırılan 765 s. TCK ile 647 s. İnfaz Kanunundan önemli bir farklılık içermektedir.

Mahkûm olunan ceza, *iki yıl veya daha az süreli hapis cezası* ise, ertelenebilir. Ancak, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişilerin mahkum olduğu *üç yıl veya daha az süreli hapis cezası* ertelenebilir. Bu ceza, hükmolunan *somut cezadır* (m. 51, f. 1).

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu sistemde erteleme sadece hapis cezası ile ilgili olarak kabul edilmiştir. Buna karşılık, adli para cezasının ertelenmesi söz ko-

zalar ile askeri suçlar ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların ertelenemeyeceğine dair özel kanun hükümleri saklıdır.” (İnfaz Kanunu, mad. 6, f. 3) demek suretiyle buna imkan tanınmıştır. Örneğin Askeri Ceza Kanununda bazı suçların cezalarının ertelenemeyeceği belirtilmiştir (m. 47, f. 1, bend A, birinci cümle).

Kanımızca, belli suçlar açısından mahkûm olunan cezanın ertelenemeyeceğinin kabulü, müessesenin niteliği ile bağdaşmamaktadır. Çünkü, erteleme, cezanın failin kişiliğine uydurulması çarelerinden birini oluşturmaktadır ve bu itibarla, somut olayda failin kişiliği göz önünde bulundurulmak suretiyle hakim tarafından karara bağlanmalıdır. Nitekim 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda tanımlanan suçlardan birinin işlenmesi durumunda verilecek cezaların ertelenemeyeceğine dair hüküm vardı (mad. 58, f. 2). Ancak, bu hüküm, 12.6.1979 tarih ve 2248 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Keza, TCK'nın 536 ve 537. maddelerinde tanımlanan kabahat suçlarının cezalarının ertelenemeyeceği kabul edilmişti. Ancak, bu hükümler (mad. 536, f. 6; mad. 537, f. 6), 13.11.1996 tarih ve 4209 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

¹⁴⁷ TURHAN, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 29 vd. Doktrinde, sadece hapis cezasının ertelenmesi, buna karşılık daha hafif bir ceza olan para cezasının ertelenememesi, yeni TCK'nın sisteminde bir çelişki olarak algılanarak eleştirilmektedir (ARTUK, Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2005, sh. 2765; aynı yazar, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 33;; CENTEL, Nur: *Yeni Türk Ceza Kanununda Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri Sistemi*, in: Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, Türk Ceza Hukuku Derneği yayını, Yayın No. 7, sh. 57). Belirtmek gerekir ki, bu eleştiriler, erteleme yeni TCK'nda bir şartlı atıfet müessesesi olarak değil, **hapis cezasının bir infaz şekli** olarak düzenlenmiş olmasını gözardı etmekten kaynaklanmaktadır. Nitekim, TCK'nın 51. maddesinin, erteleme koşullarını belirleyen birinci fıkrasının Anayasaya aykırılığı yönünde ileri sürülen itiraz, Anayasa Mahkemesi tarafından aşağıdaki gerekçe ile reddedilmiştir:

“... Maddenin gerekçesindeki ‘... erteleme, bir koşullu af olmaktan çıkılarak, ceza infaz kurumu haline getirilmiş ve erteleme sadece hapis cezası bakımından öngörülmüştür.’ ibaresinden, yasakoyucunun izlediği suç siyaseti gereği adli para cezalarını erteleme dışında bıraktığı anlaşılmaktadır. Erteleme hükmümlü için yasal bir hak olmayıp, toplum bakımından yararlı bir uygulama olduğu kabul edilmektedir. Ancak, suçun ağırlığı ve toplumdaki olumsuz sonuçları gözetilerek, suç, ceza-yı ve erteleme takdir ve tayin etmek yasama organının yetkisindedir. ... İtiraz konusu kural, maddede öngörülen belli koşulların gerçekleşmesi durumunda, hapis cezasının ertelenmesi konusunda hakime takdir hakkı tanımaktadır. Hakim, sonuç olarak hapis cezasına hükmettiği durumlarda, sanığın suç işlemekle pişman olup olmadığını değerlendirecek ve vardığı kanaate dayalı olarak erteleme konusunda bir karar verecektir. Yasakoyucunun erteleme sadece hapis cezası bakımından öngörmesi onun takdirinde olup; hakimin takdir yetkisi, yasada belirtilen koşullarla sınırlıdır. Erteleme, cezanın bireyselleştirilmesinde hakime takdir hakkı tanıyan bir kurum olduğu da dikkate alındığında, itiraz konusu kuralın hakimin takdir hakkını ortadan kaldırdığı söylenemez.” (Anayasa Mahk., 19.2.2009, E. 2007/69, K. 2009/26: RG: 2 Haziran 2009/27246).

nusu değildir¹⁴⁸. Bu itibarla, bir kararda hapis cezası ve adli para cezasına birlikte hükmedilmişse, sadece hapis cezası ile ilgili olarak erteleme kararı verilebilir¹⁴⁹. Hapis ve adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyet halinde, bu ceza ertelenebilecektir; buna karşılık, adli para cezasına mahkumiyet halinde ise, bu ceza ertelenemeyecektir. Bir suçtan dolayı mahkum olunan hapis cezası, erteleme kapsamında olmakla birlikte, kısa süreli olması dolayısıyla seçenek yaptırım olarak adli para cezasına hükmedilmesi durumunda (m. 50), bu ceza ertelenemeyecektir^{150,151}.

¹⁴⁸ Güvenlik tedbirlerinin erteleme kapsamında değerlendirilemeyeceği (TURHAN, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 31) izahtan varestedir.

¹⁴⁹ Yeni TCK'nın sisteminde "ertelemenin bölünmezliği kuralı"nın (ÖNDER, Tecil, sh. 149) bu bağlamda bir anlamı kalmamıştır.

¹⁵⁰ Failin birden fazla suç işlemesi dolayısıyla verilen hapis cezalarının içtima ettirilmesi durumunda bu cezaların ertelenebilip ertelenemeyeceği bir sorun teşkil etmektedir.

İleri sürülen bir fikre göre, ancak bir suçtan dolayı mahkûm olunan ceza ile ilgili olarak erteleme yoluna gidilebilir. Bu düşünce, eski İnfaz Kanununun 6. maddesindeki "işlediği bir suçtan dolayı ... mahkûm" olan kimse ifadesinin kullanılmasına dayanmaktaydı (KAYNAK, L.: *Adli Tevbih, Tecil, Cezanın Çekilmiş Sayılması*, İstanbul Barosu Mecmuası, 8(1938), sh. 522).

Buna karşılık, genellikle kabul edilen diğer fikre göre; birden fazla suçtan dolayı mahkûmiyet halinde de, kanunda belirlenmiş olan ceza sınırlarının aşılmaması koşuluyla, erteleme yoluna gidilebilir (ÖNDER, Tecil, sh. 154; DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1675; TURHAN, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 31). Bu durumda karşılaşılabilen ihtimallerden ikisi önem taşımaktadır:

Birinci ihtimal: İçtima ettirilen cezaların her biri erteleme sınırının altındadır. Bu durumda her bir cezanın ertelenmesi mümkündür (ÖNDER, Tecil, sh. 154; aynı yazar Genel Hükümler III, sh. 190).

İkinci ihtimal: İçtima ettirilen cezalardan biri erteleme sınırının altında kalmakla beraber, diğeri bu sınırın üzerindedir. Bu durumda, sınırın üzerinde kalan ceza ertelenemez (ÖNDER, Tecil, sh. 157; aynı yazar Genel Hükümler III, sh. 190). Yargıtay, bu ihtimalde erteleme yoluna gidilemeyeceği fikrindedir:

«İşlediği üç suçtan birinin cezasının ertelenmesine diğerlerinin ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi, cezaların şahsileştirilmesi ilkesinin uygulama biçimlerinden biri olan ertelemenin mahiyeti ile bağdaşmaz.»: 6. CD., 11.3.1975, 2171/2257 (YKD, Ekim 1975, sh. 100/101).

Yargıtay, bilahare bu içtihadını değiştirerek, içtima ettirilen cezaların toplamının erteleme sınırının üstüne çıkmış olması durumunda bunların ertelenemeyeceği kabul etmişti.

«İçtimaen verilen cezaların 647 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca tecil edilebilmesi için, içtimaen verilen ceza miktarının, tecil sınırını aşmaması gerekir. Aynı ayrı her suçun cezası tecil sınırı içerisinde kaldığından bahisle, içtima sonucu erteleme sınırını aşan cezaların ertelenmesi Kanuna aykırıdır.»: CGK., 23.6.1975, 8-152/175 (YKD, Kasım 1975, sh. 18 vd.). Ayrıca bkz. 5. CD., 18.10.1994, 2668/3009 (YKD, Ocak 1996, sh. 133).

«Kişi yönünden birbiriyle bağlantılı davalar birleştirilerek aynı sanığa birden çok ceza verilmesi halinde bu cezaların toplanmasıyla ortaya çıkan sonuçtaki ceza erteleme sınırını aşmışsa, cezaları ertelenmesi kanuna aykırıdır.»: 6. CD., 30.6.1981, 5367/5090 (YKD, Kasım 1981, sh. 1505 vd.).

«Birkaç suçun aynı zamanda hükme bağlanması halinde ertelenebilmesi için hapis cezaları toplamının iki yılı geçmemesi gerektiği ve sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bu sınırı aştığı gözetilmeden, müessir fiile teşebbüs ve geceleyin konut dokunulmazlığının ihlali suçundan verilen cezaların ertelenmesi, bozmayı gerektirmiştir.»: 4. CD., 16.2.1992, 7060/7788 (Erdurak, sh. 23).

«Ayrı ayrı her suçun cezası erteleme sınırı içinde kaldığından söz edilerek içtima sonucu erteleme sınırını aşan cezaların ertelenmesi yasaya aykırıdır.»: 5. CD., 8.3.1978, 695/738 (YKD, Mart 1979, sh. 430).

«Sanığa verilen temel hürriyeti bağlayıcı cezaların toplamının erteleme sınırını aşması halinde erteleme kararı verilemez.»: CGK., 31.3.1975, 4-54/69 (YKD, Şubat 1976, sh. 248); 5. CD., 5.5.1976, 1493/1473 (YKD, Aralık 1977, sh. 1751 vd.).

Yargıtay'ın bu görüşü doğrultusunda düşünce için bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 818. Yargıtay'ın bu görüşünün eleştirisi için bkz DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1675.

¹⁵¹ Yukarıdaki dipnotta zikredilen son içtihatlar ile yeni TCK'nın ertelemeye ilişkin hükümleri arasında bir çelişki bulunmamasına rağmen, Yargıtay yeni TCK yürürlüğe girdikten sonra, tekrar önceki görüşü doğrultusunda içtihatla bulunmuştur:

«Sanık hakkında kasten yaralama ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından açılan dava sonunda;

Kasten yaralama suçundan; 5237 sayılı Yasanın 86/1,86/3-e ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasına, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan ise; 6136 sayılı Yasanın 13/1 ve 5237 sayılı Yasanın 62. maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 366 YTL adli para cezasına hükmedilip, **iki suçtan verilen cezaların toplamı gözetildiğinde erteleme sınırını aşmış olduğundan verilen cezaların ertelenmesine yasal olarak yer olmadığına hükmedildiği,**

...

Ceza Genel Kurulunun ve Özel Dairelerin yerleşik uygulamalarına göre; 765 ve 647 sayılı Yasalar döneminde, aynı kararlar verilen hükümlerin ertelenmesi söz konusu olduğunda, **erteleme sınırının belirlenmesi sırasında toplam ceza miktarının nazara alındığı,**

Çok eski tarihli kararlarından beri ifade edile geldiği gibi; bu uygulamanın en önemli nedeninin, önceki sistemde cezaların içtimainı gerektiren yasal düzenlemelerin bulunması olduğu,

Bunun yanında, 647 sayılı Yasanın 6. maddesinde geçen “... biriyle mahkum olur ve **geçmişteki hali ve suç işleme hususunda eğilimine göre cezanın ertelenmesi ileride suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında mahkemece kanaat edinilirse, bu cezanın ertelenmesine hükümlenabilir. Bu halde ertelemenin sebebi hükmünde yazılır.**” ifadesinin de, bu yöndeki uygulamaya olanak sağladığı, zira, hakimın sanığın suç işleme konusundaki eğilimini değerlendirirken, birden fazla suç işlemiş bir kişinin suç işlemeye eğilimli olduğu şeklinde bir yorumla hareket edebildiği,

5237 sayılı TCY'de ise durumun daha farklı olduğu, öncelikle, cezaların içtimainın bu yasada bir kurum olarak düzenlenmeyip, sadece 5275 sayılı Yasada münhasıran koşullu salıverme ile ilgili bir müessese olarak yer aldığı, bunun dışında yeni sistemde ceza uygulaması yapılırken her suçun bağımsız olarak tek başına ele alınmasının gerektiği,

Ayrıca da; 5237 sayılı Yasanın 51. maddesinin 1. fıkrasındaki; “... *Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin; a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması, b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir....*” şeklindeki düzenlemeye bakıldığında, bu düzenlemenin 647 sayılı Yasanın 6. maddesinden çok farklı olduğu, öyle ki; burada suç işleme eğiliminden açıkça bahsedilmediği, buna karşılık, tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkemede oluşacak kanaatin sanığın suçu işledikten sonra, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlığa göre ortaya çıkması gerektiğine vurgu yapıldığı,

Şu halde, aynı anda işlenmiş iki suçtan birinin, diğeri için böyle bir kanaatin oluşumunda etkili olmaması gerektiği, bunun gibi, aynı anda işlenmiş iki suçtan birisinin ceza cins ve süresi itibarıyla erteleme kapsamı dışında kalmasının bağımsız olarak ertelemeye konu olabilecek diğer suçun cezasının ertelenmesine engel teşkil etmeyeceği,

Buna karşılık; daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı alınan mahkumiyet kararının ertelemeye engel olacağı,

Mahkûm olunan hapis cezası süresince kişi tutuklu kalmış ise, yeni TCK'nın sisteminde artık erteleme kararının verilmesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü, yeni TCK'nın sisteminde, denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde, hükümlünün, infaz kurumuna girmemesine rağmen, cezası infaz edilmiş sayılmaktadır¹⁵².

Keza, işaret etmek gerekir ki; mahkûm olunan ve fakat erteleme kapsamı dışındaki kalan hürriyeti bağlayıcı cezadan tutuklu kalınan sürenin mahsup edilmesi halinde artakalan ceza erteleme kapsamına girse bile ertelenemez (*Ertelemenin bölünmezliği kuralı*)¹⁵³.

2) Failin Geçmişine İlişkin Koşul

Yeni TCK'nın sisteminde, mahkumiyet konusu hapis cezası ile ilgili olarak “*erteleme kararının verilebilmesi için, kişinin;*

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

...

gerekir.” (m. 51, f. 1).

Buna göre, failin daha önce adli para cezasına ya da üç ay veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olması, yeni cezasının ertelenmesine engel teşkil etmemektedir¹⁵⁴. Bu itibarla, örneğin hakaret (TCK, m. 125) veya adil yargılama-

Ne 5237 sayılı Yasada, ne de bu Yasa ile birlikte ve daha sonra yürürlüğe giren ilgili mevzuatta erteleme sınırının toplam ceza miktarına göre belirlenmesini gerektiren her hangi bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı,

Görüş ve kanaati benimsenmiştir.

Buna göre; 5237 sayılı Yasa uyarınca tertip edilen cezalarla ilgili olarak Yasanın 51. maddesinde yazılı erteleme koşullarının oluşup oluşmadığı değerlendirilirken; **sanığa verilen tüm cezaların toplamına değil, her bir suç için belirlenmiş cezalara ayrı ayrı bakılmalı ve erteleme keyfiyeti her suç için diğerlerinden bağımsız olarak ayrıca takdir edilmelidir.**››: CGK, 10.4.2007, E: 2007/3-63, K. 2007/87.

¹⁵² TURHAN, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 33. Buna karşılık, yürürlükten kaldırılan TCK ve İnfaz Kanununun sisteminde ise, mahkûm olunan hapis cezası süresince kişi tutuklu kalmış olsa bile, erteleminin sair şartlarının mevcudiyeti halinde kişi ertelemekten yararlandırılmıyordu. Çünkü, bu sistemde mahkûm deneme süresini iyi halle geçirdiği takdirde "mahkûmiyet esasen vaki olmamış sayıl"acaktır (ÖNDER, Tecil, sh. 143; aynı yazar, Genel Hükümler III, sh. 189/190).

¹⁵³ ÖNDER, Tecil, sh. 148 vd. (151); aynı yazar, Genel Hükümler III, sh. 190; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 815, 831; TURHAN, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 33.

“*Erteleminin bölünmezliği kuralı*” gereğince, aynı mahkemede birden fazla suçtan dolayı yargılanan kişinin bu suçlardan birinden dolayı mahkûm olduğu cezanın ertelenmesine, diğer suçtan dolayı mahkûm olduğu cezanın ise ertelenmemesine karar verilmesi doğru bulunmamıştır: 2. CD., 10.4.1990, 3293/3818 (YKD, Ekim 1990, sh. 1550); 2. CD., 9.1.1990, 64/99 (YKD, Ağustos 1990, sh. 1231).

¹⁵⁴ Yürürlükten kaldırılan 647 s. İnfaz Kanununun 6. maddesine göre, para cezasının dışında bir ceza ile mahkûm olmak ertelemeye engel teşkil etmekteydi.

yı etkilemeye teşebbüs (TCK, m. 288) suçundan dolayı adli para cezasına mahkûm edilen kişi hakkında verilmiş olan bu mahkûmiyet hükmü, bilahare işlediği suçtan dolayı verilecek olan cezanın ertelenmesine engel teşkil etmeyecektir.

Keza, örneğin çekin karşılığını ilgili banka hesabında bulundurma yükümlülüğüne rağmen, “*üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi*” hakkında bu nedenle **adli para cezasına** mahkûmiyet hükmü (5941 s. *Çek Kanunu*, m. 5) verilmiş olması, bilahare işlediği suçtan dolayı verilecek olan cezanın ertelenmesine engel teşkil etmeyecektir. Hatta, bu adli para cezasının ödenmemesi dolayısıyla infazı bağlamında “hapis cezası” uygulaması (5941 s. *Çek Kanunu*, m. 5, f. 11) da, bilahare verilen mahkûmiyet hükmünün ertelenmesine engel teşkil etmeyecektir.

Daha önce mahkûm olunan *üç aydan fazla süreli hapis cezasının*, ertelemeye engel teşkil edebilmesi için, *kesinleşmiş olması* gerekir¹⁵⁵.

Daha önce mahkûm olunan adli para cezasının ödenmemesi dolayısıyla hükümlü hakkında yeni (5275 s.) İnfaz Kanununun 106'ncı maddesinin 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerine göre tazyik hapsinin uygulanmış olması durumunda da, yeni ceza ile ilgili olarak erteleme kararı verilebilir. Çünkü, adli para cezasının ödenmemesi halinde, kişi hakkında hapis cezası verilmemektedir. Kişi sadece tazyik hapsine tabi tutulmaktadır. Başka bir deyişle, tazyik hapsinin uygulanmasına rağmen, bu durumda, adli para cezası ceza olarak varlığını devam ettirmektedir.

Öncelikle işaret etmek gerekir ki, ertelemeye engel teşkil edecek olan mahkûmiyetin bir *hapis cezasına* ilişkin olması gerekir. Bu itibarla, failin örneğin yürürlükten kaldırılan 647 s. İnfaz Kanununun 4 veya yeni TCK'nın 50. maddesinde sözü edilen *tedbirlerden* birine mahkûm edilmesi durumunda, bu mahkûmiyet ertelemeye engel teşkil etmemektedir. Başka bir deyişle, failin daha önce hapis cezasına mahkûm edilmiş ve bu cezasının yürürlükten kaldırılan 647 s. İnfaz Kanununun 4 veya yeni TCK'nın 50'nci maddesine istinaden adli para cezasına çevrilmiş olması halinde, verilecek yeni cezanın ertelenmesi mümkündür¹⁵⁶. Çünkü, “*uygulamada asıl mahkûmiyet, bu (yürürlükten kaldırılan 647 s. Kanunun 4 veya yeni TCK'nın 50.) madde(s)i hükümlerine göre çevrilen (adli) para cezası*”dır (647 s. İnfaz K, m. 4, f. 4; 5237 s. TCK, m. 50, f. 5).

Ancak, kısa süreli hapis cezası yerine seçenек yaptırım olarak, yürürlükten kaldırılan 647 s. Kanunun 4 veya yeni TCK'nın 50. maddesi hükümlerine göre tedbire

¹⁵⁵ ARTUK, Mehmet Emin/YENİDÜNYA, Caner: *Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Ertelme Müessesesi*, in: Prof. Dr. Sahir Erman'a Armağan, İstanbul, 1999, sh. 81. Ancak, bu cezanın infaz edilmiş olması gerekmez (ÖNDER, Tecil, sh. 128/129).

¹⁵⁶ 8. CD., 8.2.1996, 16415/1711 (YKD, Temmuz 1996, sh. 1168).

hükmedilmiş olması halinde, bu tedbirin gereği yerine getirilmediği takdirde “*infaz hakimliği kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir.*” (m. 50, f. 6). İşaret etmek gerekir ki, bu durumda *hapis cezası*, asıl mahkûmiyeti oluşturduğu için (m. 50, f. 5, 6), bilahare işlenen suçtan dolayı verilen hapis cezasının ertelenmesine engel teşkil eder.

Daha önce mahkûm olduğu cezanın 765 s. TCK ile 647 s. İnfaz Kanunu hükümleri gereğince ertelenmiş olması halinde, kişiye işlediği yeni suçtan dolayı verilecek hapis cezasının ertelenmesi mümkündür. Çünkü, ertelenmiş olan önceki mahkûmiyet, deneme süresi içinde yeni bir suçun işlenmemiş olması dolayısıyla esasen vaki olmamış sayılır (765 s. TCK, m. 95, bent 2).

İşlediği birden fazla suç dolayısıyla açılmış olan kamu davalarının birinde kişi hakkında hükmolunan üç aydan fazla süreli hapis cezasının ertelenmesine karar verilmiş olabilir. Yeni TCK’nın sisteminde, bu hükmün kesinleşmiş olması halinde, devam eden diğer davalarda kişi hakkında bilahare hükmolunan hapis cezası artık ertelenemez.

Daha önceki mahkûmiyet hükmünün henüz kesinleşmemiş olması, erteleme kararı verilmesi için kanuni bir engel oluşturmamakta ise de; ertelemenin, cezanın bireyselleştirilmesi kurumu olması itibarıyla; bu mahkûmiyet göz önünde bulundurularak, kişi hakkında bilahare hükmolunan hapis cezasının ertelenmesi yönünde karar verilebilir.

Daha önceki mahkûmiyet hukuki varlığını devam ettirdiği sürece, ertelemeye engel olucu etkisini sürdürecektir. Mevzuatımızda bu konuda bir süre sınırlaması mevcut değildir¹⁵⁷.

Kişinin daha önce mahkûm olduğu cezanın hukuki sonuçları ile ortadan kalkmış olması halinde, verilecek yeni cezanın ertelenmesi mümkündür. Buna göre, önceki mahkûmiyet, genel affa uğramış olması durumunda, bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmaktadır (765 s. TCK, m. 97; 5237 s. TCK, m. 65, f. 1). Keza, örneğin “*Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar plânına ve ruhsatına uygun hâle getirmesi hâlinde(; hakkında) kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum ol(duğu) ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.*” (m. 184, f. 5). Buna göre, imar kirliliğine neden olma suçundan dolayı mahkum olduktan sonra da etkin pişmanlıkta bulun-

¹⁵⁷ «Tecilden istifade için mahkûmiyetin bulunmaması veya bu mahkûmiyetin hukuki neticeleleriyle birlikte ortadan kalkmış olması iktiza ettiğine ve ... mahkûmiyetin tekröre esas teşkil etmeyecek derecede eski olması, o mahkûmiyeti ortadan kaldıracak hukuki sebeplerden bulunmadığından, böyle bir vaziyette, (mahkûm olunan yeni) cezanın tecil olunamayacağına ... ekseriyetle karar verildi.» Yarg. İBK, 10.12.1952, 7/3 (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Ceza-III, 2. bası, Ankara 1984, sh. 529 vd; RG.: 13.3.1953/8358). Aynı doğrultuda görüş için bkz. SOYASLAN, Doğan: *Ceza Hukuku Genel Hükmeler*, Ankara 1998, sh. 614. Önder, oy çokluğu ile alınan bu kararı, "hukuki bir esasının olmaması sebebiyle çok sert telâkki eylemekte"dir (ÖNDER, Tecil, sh. 135).

labilecektir ve bu etkin pişmanlık, mahkum olunan cezayı bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırmaktadır. Bu mahkumiyet, bilahare işlenen suçtan dolayı verilecek cezanın ertelenmesine engel teşkil etmeyecektir.

Daha önceki mahkûmiyetin sebebini oluşturan fiil bilahare suç olmaktan çıkarılmış ise, artık bu mahkûmiyet ertelemeye engel teşkil etmez¹⁵⁸.

Buna karşılık, daha önce mahkûm olduğu cezanın özel affa uğramış olması ya da ceza zamanaşımına uğramış olması durumlarında, mahkûmiyet hukuki varlığını devam ettirdiği için, faile verilecek yeni cezanın ertelenmesi mümkün değildir.

Yeni TCK'nın sisteminde önceki mahkumiyet kararını veren mahkeme ile ilgili olarak bir sınırlandırma söz konusu değildir. Bu itibarla, önceki mahkumiyet örneğin askeri ceza mahkemesi tarafından da verilmiş olabilir. TCK'da suç olarak tanımlanmış bir fiilden dolayı verilen ceza, askeri ceza mahkemesi tarafından verilmiş olsa bile, yeni suçtan dolayı verilecek cezanın ertelenmesine engel olacaktır.

Keza, "aşağıdaki hâllerde hapis cezaları ertelenmez:

A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.

B) Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.

C) Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.

D) Daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkûm olunması." (Askeri Ceza Kanunu, m. 47).

Doktrinde, fail hakkında daha önce yabancı mahkemelerden verilmiş olan cezaların, yeni suçtan dolayı verilecek olan cezanın ertelenmesine engel teşkil etmeyeceği kabul edilmektedir¹⁵⁹. Ancak, işaret etmek gerekir ki; bu konuda Türkiye'nin de taraf olduğu "Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi"nde hüküm bulunmaktadır¹⁶⁰. Söz konusu Sözleşmenin 56 ve 57. maddelerine göre, taraf devletlerden birinde verilmiş bulunan mahkumiyet kararı bu ülkede hangi sonuçları doğuruyorsa, diğer taraf devletlerde de aynı sonuçları doğurabilecektir. Ancak, bunun için taraf devletler mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Türkiye'de bu konuda henüz bir

¹⁵⁸ 9. CD., 11.4.1995, 11973/2574 (YKD, Ekim 1995, sh. 1650); 9. CD., 2.2.1998, 3782/280 (YKD, Mayıs 1998, sh. 783); 10. CD., 14.9.1998, 6941/7935 (YKD, Şubat 1999, sh. 277).

¹⁵⁹ DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1679 bis; ÖNDER, Tecil, sh. 132; aynı yazar, Genel Hükümler, sh. 186.

¹⁶⁰ Türkiye, 28 Mayıs 1970 tarihinde La Haye'de imzalanan "Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi"ni onaylamıştır (Onay Kanunu tarih ve sayısı: 1.3.1977/2081. Sözleşmenin Türkçe metninin yayınlandığı RG.: 14.12.1977/16139).

kanuni düzenleme yapılmadığına göre, yabancı mahkeme kararlarının erteleme-ye engel teşkil edici bir etkisinin bulunmadığını kabul etmek gerekir.

3) Ertelemeye Liyakat Koşulu

Yeni TCK'ya göre, mahkum olduğu hapis cezası ile ilgili olarak “*erteleme kararının verilebilmesi için, kişinin;*

...

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir.” (m. 51, f. 1).

Bu koşul, erteleme kararının değerlendirilmesini gerekli kılan subjektif koşulunu oluşturmaktadır. Bu husustaki değerlendirmeler yapılırken failin suçu işledikten sonra ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınacaktır. Bu tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak mahkemede kişinin tekrar suç işlemeyeceği konusunda bir kanaatin oluşması gerekir¹⁶¹.

Bu değerlendirmeler yapılırken failin kişiliği göz önünde bulundurulacaktır. Ancak işlediği suçun niteliğinin veya suçu işleyiş tarzının, erteleme kararı verilirken ölçü olarak alınmaması gerekir.

Cezanın bireyselleştirilmesi kurumlarından biri olan erteleme konusunda verilen karar failin kişiliği ile ilgili olduğu için; suçun iştirak halinde işlenmiş olması durumunda, suç ortaklarından birinin veya bir kısmının cezasının ertelenmesi, diğerlerinin veya diğerlerinin de cezasının ertelenmesini zorunlu kılmamaktadır.

C. Erteleme Kararı

Erteleme kararı *esas mahkemesi* tarafından verilir. Erteleme kararı, mahkûmiyet kararı ile birlikte verilir¹⁶².

Erteleme kararının verilebilmesi için, failin talepte bulunması gerekmez. Mahkeme, erteleme konusunda *re'sen* karar verir¹⁶³. Failin ertelemekten feragat etme yetkisi bulunmamaktadır.

¹⁶¹ “... daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûmiyetin bulunması halinde kişinin suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması şartının ayrıca değerlendirilmesine gerek olmayacaktır. Birinci şartın gerçekleştiği hallerde ise, cezanın ertelenmesine karar verilebilmesi için kişinin suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekmektedir.”: CGK, 29.1.2013, E. 2012/2-1375, K. 2013/28; CGK, 26.3.2013, E. 2012/2-1390, K. 2013/100.

¹⁶² «Erteleme kararı duruşmayı bitirici ve mahkûmiyet hükmünün bölünmez (mütemmim) bir bölümüdür. Hükmün eklentisi değildir. Bitirici olmayan bir karar da değildir. CMUK'un 253. maddesi uyarınca duruşmanın sonunda ve mahkûmiyet hükmü ile birlikte verilmelidir.»: CGK., 18.11.1980, 7-267/360 (YKD, Nisan 1981, sh. 489 vd.); CGK., 11.2.1980, 7-553/49 (YKD, Mayıs 1980, sh. 713 vd.).

Erteleme kararının verilebilmesi için sanığın mahkemede bulunması gerekmemektedir. Failin münhasıran duruşmada hazır bulunmaması, ertelemeye engel teşkil etmez¹⁶⁴.

Mahkeme, faile verdiği cezayı yukarıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda ertelemek hususunda *takdir yetkisine* sahiptir. Mahkemenin, hapis cezasının ertelenmesi veya ertelenmemesi yönündeki kararının gerekçeli olması gerekir¹⁶⁵. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 7.6.1976 tarih ve 3-4/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında bu gereklilik açık bir şekilde vurgulanmıştır¹⁶⁶. Özellikle sanık tarafından erteleme talebinde bulunulması durumunda mahkemenin bu talebi kabul veya reddetme doğrultusundaki kararının gerekçelerini göstermesi gerekmektedir¹⁶⁷. Ancak, bu gerekçe salt kanun metninin tekrarı şeklinde olmamalıdır^{168,169}.

¹⁶³ «Cezaların ertelenmesi talebe bağlı olmadığı cihetle, yasal koşulları bulunduğu takdirde, re'sen de nazara alınması gerektiği düşünülmeyen, talep olmadığı gerekçesiyle, ertelemeye yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.»: 2. CD., 23.2.1982, 1188/1158 (Çağlayan I[3], sh. 990).

¹⁶⁴ 9. CD., 14.4.1978, 1534/1665 (Önder, Genel Hükümler III, sh. 199).

¹⁶⁵ Aynı doğrultuda görüş için bkz. ÖNDER, Tecil, sh. 228.. Ancak, *Dönmezer/Erman*, failin cezasının mahkeme tarafından ertelenmemesi durumunda ve hatta, erteleme talebinin reddedilmesi durumunda bunun gerekçesinin kararda gösterilmesinin gerekli olmadığı fikrindedir (DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1687).

¹⁶⁶ «TCK'nın 89. ve 647 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı "erteleme"ye karar veren hakim gerekçesini de göstermesi doğaldır. Zira, ceza vermenin amacı, o cezanın yerine getirilmesini (çektirilmesini) de içine alır. Aksi halde, ceza vermeden beklenen "önleme" (ibreti müessire) vasfı kaybolur. Bu nedenledir ki, Yasa, tertip ettiği cezanın çektirilmesine karar veren hakim, niçin bu genel kuraldan ayrıldığını, kararında belirtmeyi zorunlu kılmıştır. Gerçekten aynı Yasa maddesinde istegin reddi halinde gerekçe gösterilmesini öngören bir hükme rastlanmamaktadır. Ancak, bu sukûtin "gerekçeye lüzum olmadığı" anlamında kabulü olasılığı da yoktur.

1924 tarihli Anayasamızda mahkeme kararının gerekçeli olmasına dair bir madde mevcut olmamasına mukabil, 1961 Anayasasının 135/son maddesinde "Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır" ilkesi yer almış ve buna paralel olarak CMUK'un 32. maddesi "bütün hakimlik ve mahkemelerin her türlü kararları muhalefet şerhleri dahil gerekçeli olarak yazılır" şeklindeki metniyle yoruma yer bırakmayacak biçimde "gerekçe" zorunluluğunu kabul etmiştir.»: Yarg. İBBGK, 7.6.1976, 3-4/3 (YKD, Ağustos 1976, sh. 1197 vd.). Ayrıca bkz. 7. CD., 1.7.1976, 5454/5684 (YKD, Şubat 1979, sh. 300).

¹⁶⁷ «Sanığın, suç gününde onsekiz yaşını doldurmadığı ve hakkında TCK'nın 55/3. maddesinin uygulandığı, belirlenen ceza da erteleme sınırları içinde bulunduğu ve sanık vekili de son oturumda verdiği savunma dilekçesinde bu yönün gözönünde bulundurulmasını istediği halde, bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir.»: 5. CD., 5.2.1980, 30/218 (YKD Eylül 1980, sh. 1299).

«Sanık vekilinin cezanın tecili hususundaki istemine ilişkin yerel mahkemece olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi yasaya aykırıdır.»: CGK., 12.3.1990, 1-47/67 (Savaş/Mollamahmutoğlu I[1], sh. 1204).

¹⁶⁸ «Anayasa ve gerekse yasalarda nelerin gerekçe olabileceği sınırlı bir şekilde sayılmamıştır. Bununla beraber gösterilecek gerekçenin sanığın kişiliği ile ilgili bilgi ve belgelerin isabetle takdir edildiğini gösterir biçimde geçerli ve yasal olması aranmalıdır. Gerekçenin bu niteliği Yasa koyucunun amacına uygun olduğu gibi, kararı aydınlatmak, keyfiliği önlemek ve tarafları tatmin etmek niteliği de tartışma göstermez bir gerçektir.»: Yarg. İBBGK, 7.6.1976, 3-4/3 (YKD, Ağustos 1976, sh. 1197 vd.).

«Yasalarda tanımlanmayan gerekçe, delillerle sonuç arasındaki bağıdır. Hangi sebepten dolayı bu sonuca varıldığı anlatılması gerekçedir. Gerekçe; takdirin akla, hukuka ve dosyaya uygun açıklamasıdır. Gerekçede bulunması gereken noktalar, CMUK'un 260. maddesinde gösterilmiştir. Ancak, nelerin gerekçe olabileceği Anayasada ve Yargılama Yasasında sınırlı bir biçimde sayılmamıştır.

“Erteleme”, cezanın doğrudan doğruya sanığın kişiliğine uydurulmasını öngören yargısal bir şahısleştirme kurumudur. ... Erteleme isteminin reddi halinde mahkemece yasal bir gerekçe gösterilmeli ve *gösterilecek gerekçe, sanığın kişiliği ile ilgili bilgi ve belgelerin isabetle değerlendirildiğini gösterir biçimde olmalıdır*. Gerekçenin açıklanan bu niteliği Yasa koyucunun amacına uygun olduğu gibi kararı aydınlatmak, keyfiliği önlemek ve tarafları tatmin etmek özelliklerini de taşımaktadır.

Cezanın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin takdir, mutlaka yasal olmalı, sanığın kişiliğine dayanmalı ve olay ile uyumlu bulunmalıdır. Esasen, bu hususta gerekçe gösterilme zorunluluğundan güdülen amaç: 647 sayılı Yasanın 6. maddesinde yazılı yasal nedenlere dayandırılmak kaydı ve şartı ile, gerekçede bu hususta gösterilen nedenlerin *yargıcın sadece soyut kanılarını değil*, ölçünün isabetle seçildiğini doğrulayıp açıklayan ve dosya içeriğine, sanığın duruşmada gözlenen haline uygun bir değerlendirme sonucu takdir hakkının yerinde kullanılıp kullanılmadığının saptanmasıdır.

Ertelemeye yer olmadığına ilişkin karar, sanığın kişiliğinde var olan nedenlere dayanmalıdır. Sanığın geçmişteki kişiliği tartışılarak ilerde suç işleme eğilimi değerlendirilmeli ve sonucuna göre cezasının ertelenmesine yer olup olmadığı karara bağlanmalıdır.

Ayrıca, gösterilen gerekçenin kendi içinde de çelişmemesi gerekir. *Yasa metnini tekrar etmek gerekçe olmadığı* gibi suçun unsurları ya da cezayı ağırlaştırıcı sebepler de gerekçe kabul edilemez. Yerel mahkemece, sanıkların geçmişteki halleri irdelenmeden, gelecekteki suç işleme eğilimi değerlendirilmeden, “TCK’nın 80. maddesinin uygulanmasını gerektiren teselsül nedeniyle olumlu kaniya varılmadığından bahisle” yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile cezalarının ertelenmesine yer olmadığına karar verilemez.»: CGK., 31.1.1994, 5-306/10 (YKD, Ağustos 1994, sh. 1324 vd.).

«Gerekçe; istem konusundaki takdirin akla, hukuka ve dosya içerisindeki bilgi ve belgelere üstün açıklamasıdır. Ertelemeye yer olmadığına karar verilirken gösterilen gerekçenin soruşturma aşamasında izlenen sanığın kişiliği ile ilgili bilgi ve belgelerin yerinde değerlendirildiğini gösterir biçimde: geçerli yeterli ve yasal olması zorunludur. Yasal, yeterli ve geçerli olmayan bir gerekçeye dayanılarak erteleme isteminin reddine karar verilmesi yasa koyucunun amacına uygun düşmeyeceği gibi, cezanın kişiselleştirilmesi ilkesine de aykırıdır ve uygulamada keyfiliğe yol açar. Keyfiliği önlemek, tarafları tatmin etmek ve kararı aydınlatmak için; *sanığın olay öncesi ve sonrası davranışları gözönünde bulundurularak, gelecekteki yaşamı sezilmeli, sanığın suç işleme hususundaki eğilimi değerlendirilmelidir*.»: CGK. 3.10.1995, 3-244/267 (YKD, Ocak 1996, sh. 100 vd.). Ayrıca bkz. CGK., 25.12.1989, 2-350/412 (YKD, Aralık 1990, sh. 1816 vd.); CGK., 26.12.1994, 9-362/371 (YKD, Ağustos 1995); 1. CD., 26.3.1991, 631/835 (YKD, Temmuz 1991); 1. CD., 13.2.1990, 299/255 (YKD, Mayıs 1990, sh. 742 vd.).

647 sayılı Kanunun 6. maddesinde cürümler arasında herhangi bir ayırım yapılmadığı halde, yerel mahkemenin, “*sanığın aynı neviden suç işlemekten çekineceği kanaatini vermediğinden*” bahisle cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar vermesi» doğru değildir: CGK., 3.10.1988, 3-283/332 (YKD, Şubat 1989, sh. 258 vd.).

¹⁶⁹ «TCK’nın 59. maddesinin uygulanmasını gerektiren hallerin neler olduğu Kanun metninde sınırlandırılmamıştır. Kanun koyucu, bir suçu oluşturan unsurlarla çatışmamak veya yasal indirim sınırlarını geçmemek kaydıyla hakime geniş bir takdir yetkisi tanımış; hatta, uygulamadaki çeşitli halleri kapsayacak bir kalıp bulmanın zorluğu karşısında bir tanımlama yapmaktan isteyerek kaçınmıştır. Her olayın özelliği dikkate alınarak tertip edilecek cezanın, suçlunun kişiliğine ve suça uydurulması suretiyle daha insancıl koşullarla dengeli bir adaletin tahakkuku amaç edinilmiştir. Böylece, belirtilen ilkelerin dikkate alınması suretiyle *hüküm anına kadar sanığın davranışlarını*

Kanun, erteleme işleniş süreciyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen tazmini şartına bağlanmasını öngörmektedir:

“Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi koşulu-na bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl salıverilir.” (m. 51, f. 2).

Dikkat edilmelidir ki, işlediği suç dolayısıyla mağdurun veya kamunun uğradığı zararı tamamen tazmin etmesi halinde, hükümlü infaz kurumuna girmekten kurtulabilecektir. Bu itibarla, koşullu erteleme kararına rağmen, işlediği suç dolayısıyla mağdurun veya kamunun uğradığı zararı tamamen tazmin etmediği takdirde, hükümlünün cezasının infaz kurumunda çektirilmesine başlanacaktır. Ancak, mağdurun veya kamunun uğradığı zarar tamamen tazmin edildiği takdirde, cezanın infaz kurumunda çektirilmesine derhal son verilir. Ancak, bu hususta hükmü veren mahkemenin karar vermesi gerekir.

Bu bağlamda tazmini söz konusu olan zarar, sadece **maddi zararlar**dır. Erteleme kararı verilebilmesi için, manevi zararların tazmini şart olarak aranamaz.

değerlendiren hakim, TCK'nın 59. maddesini uygularken, yerleşmiş içtihatlarla göre göstereceği gerekçe bir şekilde bağlanmamış ise de, geçerli olması koşulu aranmıştır.

Buna karşın TCK'nın 89 ve 647 sayılı Kanunun 6. maddelerinde yer alan “erteleme” müessesesinin uygulanabilmesi anılan maddede yazılı unsurların mevcudiyetine bağlı bulunmuştur. Erteleme, doğrudan doğruya cezanın sanığın kişiliğine uydurulmasını öngören yargısal şahısileştirme müessesesi olup, uygulanabilmesi için, sanığın sübjektif koşula “iyi hal” niteliğine sahip bulunması gerekir. Diğer bir deyişle, TCK'nın 59. maddesinin uygulanması koşullarını hükümden önceki aşamalarda arayacak hakim, cezayı ertelerken sanığın “geleceğini” sezmeye, o zamana kadar elde ettiği olumlu izlenimlerin gelecekte devam edip etmeyeceğini takdir etmesi gerekir.

Yasalarımızda mevcut takdiri indirim nedenleri ile erteleme, birbirinden ayrı bağımsız müesseselerdir. Bir ceza davasında takdiri indirim sebebinin kabul eden hakim, takdire bırakılan bütün müesseseleri aynı açıdan değerlendirmesi ise düşünülemez. Ancak, TCK'nın 59. maddesinin uygulanması için değerlendirilen hal, erteleme için Yasada aranan koşulları da kapsayan ortak bir neden teşkil ederse, bu takdirde olayın özelliğine göre hakim, ertelemedeki yetkisini de sanık lehine kullanması gerekir. aksi takdirde, kurduğu hükümle çelişkiye düşeceği ve bu halin güven sarsıcı bulunacağı açıktır.»: Yarg. İBBGK, 7.6.1976, 3-4/3 (YKD, Ağustos 1976, sh. 1197 vd.).

Ancak, Yargıtay'ın bu İçtihadı Birleştirme Kararı ile çelişen pek çok kararı mevcuttur:

«Yerel Mahkeme; “Sanığın sabıkasız oluşu ve ahlâkî temayülleri” hususunda olumlu bir kanaate vardığını açıklayarak, hakkında TCK'nın 59. maddesi ile cezadan indirim yaptığı halde, “sanığın geçmişteki ahlaki temayülleri göre cezasının ertelenmesi halinde ilerde bir daha suç işlemeyeceği yolunda mahkemeye kanaat gelmediği” açıklaması ile cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar vermiştir. Yerel Mahkeme, TCK'nın 59. maddesi ile cezadan indirim yaparken, TCK'nın 89 ve 647 sayılı Yasanın 6. maddesinde öngörülen nedenleri değerlendirip, olumlu bularak uygulama yapmış; bilahare aynı gerekçeyi olumsuz tarafından benimseyerek ertelemeye yer olmadığına karar vermek suretiyle, gerekçede çelişkiye düşmüştür.»: CGK., 20.12.1993, 10-304/337 (YKD. Haziran 1994, sh. 981 vd.). Ayrıca bkz. CGK., 25.5.1992, 4-96/160 (YKD, Ağustos 1992, sh. 1276 vd.); CGK., 19.3.1990, 2-54/75 (YKD, Ocak 1991, sh. 97 vd.); CGK., 7.12.1979, 7-502/574 (YKD, Mart 1980, sh. 415 vd.).

Gerçek veya tüzel kişilerin uğradığı zararların yanı sıra, maddi nitelikte olmak koşuluyla, kamusal nitelikli zararları da bu kapsamda mütalâa etmek gerekir¹⁷⁰.

Zarar miktarı, **nispi muhakeme** yöntemiyle tespit edilmelidir.

Hapis cezası, mahkumiyet hükmünde belirlenen **zarar miktarının tamamının** ödenmesi koşuluyla ertelenebilir. Bu itibarla uğranılan zararın kısmen ödenmesi halinde, bu şart gerçekleşmiş sayılamaz¹⁷¹.

İşlenen suç dolayısıyla oluşan zarar tamamen tazmin edilmediği takdirde, hapis cezasının ertelenmesine karar verilmemelidir. Her ne kadar maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki ifade, işlenen suç dolayısıyla bir zararın oluşması halinde de mahkemenin erteleme kararı verme hususunda takdir yetkisinin olduğu şeklinde anlaşılabilir ise de; kısmen tazmin halinde, cezanın ertelenmesine imkan tanımayan bir sistemde, zararın hiç karşılanmaması halinde cezanın ertelenmesine imkan tanındığını kabul etmek bir çelişki olur. Bu itibarla, yeni TCK'nın sisteminde, **işlenen suç dolayısıyla bir zararın oluşması halinde, bu zarar tazmin edilmediği takdirde, cezanın ertelenmesine karar verilemeyecektir.**

Yeni TCK'nın sisteminde, hapis cezasının zararın tazmini şartına bağlı olarak ertelenmesine karar verilebilmesi için, suçtan zarar gören gerçek veya tüzel kişilerin talepte bulunması gerekmemektedir^{172, 173}.

¹⁷⁰ Kitabımızın ilk üç basısında, burada tazmini söz konusu olan zararların maddi ve manevi zararları kapsayacak şekilde geniş yorumlanması gerektiği yönünde açıklama yer almakta idi. Kanunun ruhuyla bağdaşmayan bu açıklamayı, dördüncü bası itibarıyla değiştirmiş bulunmaktayız.

¹⁷¹ EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 837/838.

¹⁷² Buna karşılık, 765 s. TCK'nın sistemi bakımından doktrinde kabul edilen görüşe göre; tazmin şartına bağlı olarak ertelemeye karar verilebilmesi için, mağdurun failden şahsi haklarının tazminini talep etmiş olması gerekmektedir: EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 838; ÖNDER, Tecil, sh. 287; aynı yazar, Genel Hükümler III, sh. 202.

Yargıtay'ın görüşü de aynı yöndeydi:

«Özel Daire ile Yerel mahkeme arasında oluş ve subutta bir uyumsuzluk bulunmayıp, çözülecek sorun şahsi hak istemi bulunmadığı halde ertelemenin şahsi hakkın tazmini koşuluna bağlı tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Ertelemenin, şahsi hakların tazmini koşuluna bağlanabilmesi için; suçtan zarar görenin davaya müdahil sıfatıyla katılması ve şahsi hak isteminde bulunması gerekir.»: CGK., 29.6.1999, 11-179/189 (YKD, Eylül 1999, sh. 1291 vd.).

¹⁷³ *Turhan*, mahkemenin tazmin şartına bağlı olarak ertelemeye karar vermeden önce suçtan zarar göreni çağırarak, uğradığı zararın tazminini isteyip istemediğini sorması gerektiği düşüncesindedir. Buna göre, suçtan zarar görenin hukuk mahkemesine başvurarak tazminat talebinde bulunacağını beyan etmesi halinde, mahkemenin ertelemeyi zararın tazmini şartına bağlamaması gerekir (TURHAN, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 38 vd.).

Kanaatimizce, erteleme kararında belirlenen tazminat miktarının zararı tamamen karşılaması gerekmektedir. Suçtan zarar görenin, belirlenen tazminat miktarının, zararını tamamen karşılandığını kabul etmemesi halinde; zararın tazmini koşuluna bağlı olarak erteleme kararı verilmemelidir.

D. Erteleme Kararının Sonuçları, Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri

Hapis cezası ile ilgili olarak ertelenme kararının verilmesi, bu cezanın infaz kurumunda çektirilmesine engel olur. Hapis cezasına mahkûm olan ve cezası ertelenen kişi tutuklu ise, derhal serbest bırakılır. Bunun için, erteleme kararının kesinleşmesi gerekmez.

Serbest bırakılan mahkûm, belli bir süre denetime tabi tutulur. Bu süreye yeni TCK’da **denetim süresi** denmektedir:

“Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.” (m. 51, f. 3).

Buna göre, yeni TCK’da maktu bir denetim süresi kabul edilmemiştir¹⁷⁴. Böylece mahkeme hükmettiği hapis cezasının ertelenmesi yönünde karar verirken, mahkumiyet kararında faille ilgili olarak *“bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere”* bir denetim süresi belirleyecektir. Ancak, belirlenen denetim süresi, *“mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.”* Bu düzenlemeye göre, denetim süresi, üç yılı aşmamak koşuluyla, hükmolunan hapis cezasının süresinden fazla olabilecektir.

Denetim süresinin, hüküm tarihinden itibaren değil, **hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren** işletilmesi gerekir. Çünkü, yeni TCK’da erteleme, bir *infaz rejimi* olarak düzenlenmiştir¹⁷⁵. Hüküm kesinleşmeden cezanın infazına başlanamayacağına göre; denetim süresinin hükmün kesinleşme tarihinden önce işletilmeye başlatılması, hükmolunan denetimli serbestlik tedbirinin (m. 51, f. 4) uygulanmasını imkansız kılar¹⁷⁶.

Yeni TCK’nın sisteminde, hapis cezasının ertelenmesine karar veren mahkeme ayrıca, hükümlü hakkında denetim süresi içinde **denetimli serbestlik tedbiri** uygulanmasına karar verebilecektir:

“Denetim süresi içinde;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,

¹⁷⁴ Bu bakımdan, doktrinde ileri sürülen görüşler (İÇEL, TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, sh. 340; ÖNDER, Tecil, sh. 241 vd.), yeni TCK’nın hazırlanmasında göz önünde bulundurulmuştur.

¹⁷⁵ TURHAN, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 40.

¹⁷⁶ CGK., 23.6.1980, 8-153/247 (Savaş/Mollamahmutoğlu I[1], sh. 1231/1232). Aksi doğrultuda, yani deneme süresinin başlaması için hükmün verilmesini yeterli gören karar için bkz. CGK., 6.12.1982, 2-335/465 (Savaş/Mollamahmutoğlu I[1], sh. 1228 vd.). Ertelemeyi hapis cezasının bir infaz şekli olarak kabul eden yeni TCK’nın sistemine rağmen, Centel, hala CGK’nun aksi doğrultudaki içtihadını benimsemektedir (CENTEL, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 58).

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,

mahkemece karar verilebilir.” (m. 51, f. 4).

“Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek infaz hâkimine verir.” (m. 51, f. 5).

“Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.” (m. 51, f. 6).

TCK’nın bu düzenlemesinde, doktrinde ileri sürülen görüşler¹⁷⁷ dikkate alınmıştır.

Yeni TCK’nın sisteminde erteleme bir ceza infaz rejimi olarak düzenlendiği için, hapis cezasının ertelenmesine rağmen, bu cezaya mahkumiyete bağlı hak yoksunlukları, kişi açısından etkisini doğuracaktır.

Ancak, “mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen ... hükümlü.. kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlik yetkileri”ni kullanabilecektir (m. 53, f. 3).

Keza, “mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü”nün, “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra” edebilmesine hükmü veren mahkemece karar verilebilir (m. 53, f. 1, bent e; f. 3).

Yine, ertelenen hapis cezası kısa süreli ise, hükümlü hakkında bu cezaya mahkumiyete bağlı hak yoksunluğu doğmaz. (m. 53, f. 4)

1) Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi, Bu Süre Zarfında Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklerle Uygun Davranılmış Olması

Hapis cezası ertelenmiş olan mahkûmun denetim süresini iyi halli olarak geçirmesi, bu süre zarfında kasıtlı bir suç işlememesi ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerle uygun davranmış olması halinde, yeni TCK’ya göre

¹⁷⁷ İÇEL, TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, sh. 339/340; ÖNDER, Tecil, sh., 269/270, 279 vd.

cezası infaz edilmiş sayılır (m. 51, f. 8)¹⁷⁸. Bu sonuç için, ayrıca bir karar verilmesine gerek yoktur. Denetim süresinin iyi halle geçirilmiş olması halinde bu sonuç kendiliğinden doğar.

2) Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülükler Uygun Davranılmamış Olması

Cezası ertelenen hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülükler uygun davranılmamış olması halinde yapılacak işlemler, 51'inci maddenin yedinci fıkrasında belirlenmiştir:

“Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülükler, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, uymakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine infaz hakimliğince karar verilir.”

a) Hükümlü, denetim süresi içinde **kasıtlı** bir **suç** işlemiş olabilir¹⁷⁹. Bu durumda, *denetim süresi içinde işlenen suçtan dolayı infaz hakimî*, erteleme kararını geri alarak, *“ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar”* verir. Buna karşılık, denetim süresi içinde taksirle işlenmiş olan suç, erteleme kararının geri alınmasını gerektirmez¹⁸⁰.

İşaret etmek gerekir ki, erteleme kararının geri alınmasını gerektiren suç, denetim süresi içinde işlenmiş olmalıdır. Bu itibarla, ertelenmiş mahkûmiyet kararından önce işlenmiş olan başka bir suçtan dolayı bilahare denetim süresi içinde yeni bir mahkûmiyet kararının verilmesi durumunda, erteleme kararı geri alınmaz¹⁸¹.

¹⁷⁸ Halbuki bu durumda 765 sayılı TCK'nın sisteminde “mahkûmiyet esasen vaki olmamış” sayılırdı (m. 95). Böylece, “vaki olmamış sayılan bu mahkûmiyet”, failin bilahare işleyeceği suçlar açısından ertelemeye engel teşkil etmemekteydi; failin bilahare işleyeceği suçların cezasının tekrür nedeniyle artırılmasına sebebiyet vermemekteydi.

¹⁷⁹ Deneme süresi içinde işlenen suçun yabancı bir ülkede işlenmesi durumuyla ilgili olarak bkz. ÖNDER, Tecil, sh. 304 vd.; DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1710.

¹⁸⁰ 765 s. TCK'nda bir açıklık olmamakla beraber; Yargıtay, deneme süresi içinde işlenen cürmün ancak *kasten* işlenen bir suç olabileceği içtihadında bulunmuştu:

«Önceki erteli hükümlülüğün kasdî suça ilişkin bulunduğu, bu suçtan kurulan hükmün ise, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet verme suçuna yönelik olduğu, TCK'nın 95. maddesindeki “işlemek” sözcüğünün, kasdî suçlara münhasır bulunduğu gözetilmeden sanığın erteli hükümlülüğünün aynen çektirilmesine karar verilmesi, kanuna aykırıdır.»: 9. CD., 14.4.1997, 5657/2795 (YKD, Haziran 1997, sh. 1015).

¹⁸¹ EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 846.

«Hükümlü, deneme süresi içinde bir suç işlemezse “hükümlülüğü vaki olmamış sayılır”. Deneme müddeti hüküm tarihinden itibaren yürümeğe başlar.

Ertelenen düşmesi için sonraki suçun deneme müddeti içinde işlenmiş olması ve aynı zamanda yine deneme müddeti içinde mahkûmiyet kararı verilmiş olması lazımdır.

Erteleme kararının geri alınması için, denetim süresi içinde yeni bir suçun işlenmiş olması yeterlidir¹⁸². Denetim süresinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet kararının da bu süre içinde verilmesi gerekmemektedir¹⁸³.

Denetim süresi içinde işlenen kasıtlı suçtan dolayı hapis veya adli para cezasına ya da güvenlik tedbirine hükmedilmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Bu itibarla, denetim süresi içinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan hapis cezası 50'nci madde hükümlerine göre seçenek yaptırım olarak güvenlik tedbirine çevrilmiş olsa bile, erteleme kararının geri alınması gerekir.

Erteleme kararının geri alınmasına karar veren infaz hakimi, “*ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar*” verir. Bu durumda, her iki ceza gerçek içtima hükümlerine göre ayrı ayrı infaz edilir.

b) Hükümlü, denetimli serbestlik tedbirinin gereği olan yükümlülüklerle uymayabilir. Bu durumda da infaz hakimi, erteleme kararını geri alarak, “*ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar*” verir. Ancak, bunun için, önce infaz hakiminin hükümlüye uyarıda bulunması ve bu uyarıya rağmen hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinin gereği olan yükümlülüklerine uymamakta ısrar etmesi gerekir.

Belirtilen durumlarda, erteleme kararı kendiliğinden düşmemektedir, erteleme kararının geri alınması konusunda infaz hakimliğince karar verilmelidir. Bu nedenle, yeni TCK'nın sisteminde “erteleme kararının düşmesi”nden söz edilemez.

Olayımızda ertelenmiş hüküm 14.12.1990 tarihinde karara bağlandığı halde, ikinci suç 4.9.1990 tarihinde, yani deneme müddeti başlamadan önce işlenmiştir. Bu itibarla TCK'nın 95/2. maddesinde öngörülen koşul gerçekleşmemiştir.»: 10. CD., 2.2.1993, 664/1008 (YKD, Mayıs 1993, sh. 803 vd.).

Önder de deneme süresinden önce işlenmiş olan suçtan dolayı bilahare verilen mahkûmiyet kararının erteleme kararını düşüreceği fikrindedir (ÖNDER, Tecil, sh. 312).

¹⁸² ÖNDER, Tecil, sh. 302, 337; aynı yazar, Genel Hükümler III, sh. 207; DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1708; ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku(2), sh. 310. Ayrıca bkz. TCK '98 Tasarısı, mad. 81, f. 10 gerekçesi (sh. 194).

¹⁸³ «TCK'nın 95. maddesine göre, tecilde deneme süresi hükmün verildiği tarihten başlar. Tecilin düşmesi için sonraki suçun deneme süresi içinde işlenmiş olması yeterli olup, ayrıca hükmün de Kanunda belirlenen bu süre içinde verilmesine gerek yoktur.»: CGK., 3.4.1989, 5-73/129 (YKD, Ağustos 1989, sh. 1177 vd.).

Ancak, Erem/Danişman/Artuk, madde metnindeki “mahkûm” olmak ifadesini lafzen yorumlayarak, erteleme kararının düşmesi için deneme süresi içinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet kararının da deneme süresi içinde verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Hatta, bu görüşe göre, bu mahkûmiyet hükmünün deneme süresi içinde kesinleşmesi gerekmektedir (EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 845).

Yargıtay da bilahare bu görüşe taraftar olmuştur: «Ertelemenin düşmesi için sonraki suçun deneme müddeti içinde işlenmiş olması ve aynı zamanda yine deneme müddeti içinde mahkûmiyete karar verilmiş olması lazımdır.»: 10. CD., 2.2.1993, 664/1008 (YKD, Mayıs 1993, sh. 803).

IX. Koşullu Salıverilme

A. Amacı ve Hukuki Niteliği

Suç işleyen kişinin belli bir cezaya mahkûm edilmesiyle güdülen amaç, genel ve özel önleme olarak belirlenmiş ise de; bunlardan özel önlemenin ve suçlunun yeniden topluma kazandırılmasının gerçekleşmesi, ceza infaz kurumlarının içinde bulunduğu koşullar karşısında çok zordur. Ön plana çıkan önleme ve suçluyu tekrar topluma kazandırma amacına rağmen, cezanın kişiyi belli yoksunluklara maruz bırakma yönünün varlığı kuşkusuzdur.

İşlediği suç nedeniyle mahkûm olduğu **hapis cezasını infaz kurumunda çekmeye başlayan insanın** kişiliğini geliştirebilmesi için **özgürlüğüne tekrar kavuşturulması gerekir**. Hapis cezasına mahkûm olan ve bu cezanın infazı amacıyla cezaevine giren insan, cezanın yoksunluğa maruz bırakma özelliğinin sonucu olarak, işlediği suçtan dolayı etkin bir pişmanlık duymalıdır. Ceza infaz kurumunda cezasını çekmekte olan ve bunun sonucu olarak belli bir ıslah ve terbiye programına tabi tutulan ve bütün tutum ve davranışları gözlemlenen mahkûmun işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyması halinde, mahkûm olduğu ceza süresi tamamlanmadan infaz kurumunun dışına çıkarılmasına ve cezasının kalan kısmını herhangi bir suç işlememesi ve kendisine yüklenen yükümlülöklere uygun davranması koşuluyla dışarıda geçirmesine imkan tanınmaktadır. Hapis cezasının bir **infaz rejimi** olan bu kuruma, **koşullu salıverilme** (*şartla salıverilme, meşruten tahliye*) adı verilmektedir¹⁸⁴.

Koşullu salıverilme, hapis cezasının bireyselleşmesini sağlama açısından bir araçtır. Bu kurum sayesinde, mahkûm olduğu ceza süresi dolmadan infaz kurumunun dışına çıkacağı ve böylece özgürlüğüne kavuşacağı ümit ve beklentisiyle kişi kendisiyle ilgili olarak uygulanan ıslah ve terbiye programının gereklerine uygun davranabilmektedir. Yani, koşullu salıverilme, mahkûmları iyi halli olmaya teşvik etmektedir.

Ancak, kendisiyle ilgili olarak uygulanan ıslah ve terbiye programının gereklerine uygun davrandığı ve işlediği suç dolayısıyla etkin pişmanlık duyduğu için, mahkûm olduğu ceza süresi tamamlanmadan serbest bırakılan mahkûmun dışarıda geçirdiği sürenin de iyi halli olması gerekir. Bu nedenle, serbest bırakılan mahkûm, cezasının kalan kısmını infaz kurumu dışında, toplumsal ortamda çekerken belirli bir çerçeve içinde denetim altında tutulmakta ve bu suretle toplum hayatına yeniden uyumu sağlanmaktadır. Serbest bırakılan mahkûm, bu denetim sayesinde toplum içinde kendi başına buyruk bir vaziyette bırakılmamakta ve tekrar suç işlemesi önlenmektedir¹⁸⁵.

¹⁸⁴ YENİDÜNYA, Ahmet Caner: *Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme*, İstanbul, Eylül 2002, sh. 79 vd.

¹⁸⁵ Anayasa Mahkemesinin **24.10.2019** tarihli ve 2016/7271 bireysel başvuru sayılı Kararı, kn. 43.

Önemle işaret etmemiz gerekir ki; koşullu salıverilme kurumunun öngörülen amacı gerçekleştirebilmesi için, mahkûmun infaz kurumunda uygun ıslah ve terbiye programına tabi tutulması ve dışarı çıkarıldıktan sonra da tutum ve davranışlarının gözetim altında tutulması gerekmektedir.

Fakat, özellikle ülkemiz uygulamasında koşullu salıverilmenin rutinleştirilmesi, infaz kurumunda geçirilen sürenin iyi halliliği konusundaki esneklik ve ayrıca, infaz kurumu dışında geçirilen süre içinde sağlıklı bir gözetim sisteminin olmayışı, bu kurum açısından ciddi bir eleştiri konusu yapılmaktadır¹⁸⁶. Ayrıca, koşullu salıverilmenin, zamanla yetersiz kalan cezaevlerini boşaltmak, cezaevlerindeki mahkûm sayısını azaltmak gibi sosyal ve ekonomik düşüncelerle kabul edilmesi halinde; sözünü ettiğimiz gerekçelerin ve dolayısıyla hukuki görüşün göz ardı edildiğini hatırlatmak gerekir.

Örneğin İnfaz Kanununda son olarak 14.4.2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile sağlanan “koşullu” tahliyelerin, infaz amaçlarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır; aksine bu tahliyelerle güdülen amacın, kapasite sınırı oldukça aşılmış bulunan infaz kurumlarında yer açılması olduğunu itiraf etmek gerekir.

B. Koşulları

1) Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Koşullar

Öncelikle belirtelim ki; esas itibarıyla 5275 sayılı **İnfaz Kanununda** (m. 107) düzenlenmiş olan koşullu salıverilme, niteliği gereği olarak, sadece *hapis cezası* bakımından kabul edilmiş olan bir kurumdur. Bu itibarla, mahkûm olunan hapis cezasının ancak belli bir kısmı infaz kurumunda çekildikten sonra koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.

İnfaz Kanununda, koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûm olunan hapis cezasının belirli bir miktarının infaz kurumunda çekilmesi gerekmektedir. **Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için hapis cezasının “infaz kurumunda” çekilmesi gereken miktarı, mahkumiyetin sebebini oluşturan suçla göre değişmektedir¹⁸⁷.**

I. Süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde kural olarak, mahkum olunan cezanın **yarısının** “infaz kurumunda” çekilmesi gerekmektedir. Ancak, aşağıda sayılan suçlardan **süreli hapis cezasına** mahkumiyet halinde, koşullu salıveril-

¹⁸⁶ CENTEL, Nur. *Şartla Salıverme*, in: Hukuk Araştırmaları, cilt 7, yıl 1992-1993, sayı 1-3, sh. 43; DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1717, 1718; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 853.

¹⁸⁷ Anayasa Mahkemesi, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili olarak şartla salıverme sürelerini ağırlaştıran ve dolayısıyla mahkûmun daha uzun süre ceza infaz kurumunda kalmasına yol açan bu hükmün hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğundan bahisle açılan iptal davasını reddetmiştir: 31.3.1992 tarih ve E. 1991/18, K. 1992/20 sayılı Karar (AMKD, cilt 28/I [1993], sh. 232 vd.).

meden yararlanabilmek için, mahkum olunan cezanın **üçte ikisinin** “infaz kurumunda” çekilmesi gerekmektedir:

- a) **Kasten öldürme** suçu (TCK, m. 81, 82, 83),
- b) TCK, m. 87, f. 2, bent d kapsamına giren neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu (**Kasten yaralamanın mağdurun yüzünde sürekli değişikliğe neden olması** hali),
- c) **İşkence** suçu (TCK, m. 94 ve 95),
- ç) **Eziyet** suçu (TCK, m. 96),
- d) TCK, m. 102, f. 2 kapsamına giren hariç, **Cinsel saldırı** suçu,
- e) TCK, m. 104, f. 1 kapsamına giren **Reşit olmayanla cinsel ilişki** suçu,
- f) **Cinsel taciz** suçu (TCK, m. 105),
- g) **Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar** (TCK, m. 132 ilâ 138),
- ğ) **Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk** (TCK, m. 326 ilâ 339),
- h) **Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme** suçu (TCK, m. 220, f. 1),
- ı) **Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar**,
- i) 1.1.1983 tarihli ve 2937 sayılı **Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu** kapsamına giren suçlar (İnfaz K, m. 107, f. 2).

Ancak, bu sayılan istisnai suçlar da dahil olmak üzere, “*ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını ... infaz kurumunda (iyi halli olarak) çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.*” (İnfaz K, m. 107, f. 2).

Keza, **suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan** dolayı “*ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olan (kişi, bu cezasının) otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olan (kişi ise, bu cezasının) otuz yılını ... infaz kurumunda (iyi halli olarak) çekti(ğ)i takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilir...*” (İnfaz K, m. 107, f. 4). Örneğin suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen **kasten öldürme** suçundan dolayı mahkum edilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının **otuz altı yılının**, müebbet hapis cezasının ise **otuz yılının** “infaz kurumunda” iyi halli olarak çekildiği takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir.

Yine, örneğin **yağma** (TCK, m. 148, 149), **dolandırıcılık** (TCK, m. 157, 158), **fuhuş** (TCK, m. 227), **ihaleye fesat karıştırma** (TCK, m. 235), **tefecilik** (TCK, m. 241), **kaçakçılık** (5607 s. KMK, m. 3), **tarihi eser kaçaklığı** (2863 s. K, m. 32 ve 68) suçundan dolayı mahkum olunan hapis cezasının **yarısı** “infaz ku-

rumunda” iyi halli olarak çekildiği takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılabilecektir. Ancak bu suçların **suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde**, bu suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezasının **üçte ikisi** “infaz kurumunda” iyi halli olarak çekildiği takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılabilecektir (İnfaz K, m. 107, f. 2).

Ancak belirtmek gerekir ki, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde örneğin **uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti** suçunun (TCK, m. 188) işlenmesi halinde, bu suçtan dolayı hükmolunan hapis cezasının **üçte ikisi** değil, **dörtte üçü** “infaz kurumunda” iyi halli olarak çekildiği takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılabilecektir (İnfaz K, m. 107, f. 4).

II. Aşağıda sayılan suçlardan süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde, koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için, mahkum olunan cezanın dörtte üçünün “infaz kurumunda” çekilmesi gerekmektedir:

- a) TCK, m. 102, f. 2’de tanımlanan **Cinsel saldırı** suçu (İnfaz K, m. 108, f. 9),
- b) TCK, m. 103’de tanımlanan **Çocukların cinsel istismarı** suçu (İnfaz K, m. 108, f. 9),
- c) TCK, m. 104, f. 2 ve 3’de tanımlanan **Reşit olmayanla cinsel ilişki** suçu (İnfaz K, m. 108, f. 9),
- ç) TCK, m. 188’de tanımlanan **Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti** suçu (İnfaz K, m. 108, f. 9).
- d) **Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar** (3713 s. TMK, m. 17, f. 1, ikinci cümle).

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar, 3713 s. TMK, m. 3 ve 4’te sayma yöntemiyle belirlenmiştir. Keza, bu Kanunda (m. 7, f. 2) tanımlanan **terör örgütünün propagandası** suçundan dolayı hükmolunan hapis cezasının **dörtte üçünün** infaz kurumunda çekilmesi halinde, koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir¹⁸⁸.

¹⁸⁸ 29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanuna ilişkin TBMM Adalet Komisyonunun 26.6.2006 tarihli ve Esas No: 1/1194, Karar No: 106 sayılı Raporunda **gerekçe** olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Terörle Mücadele Kanununun, Tasarının çerçeve 11’inci maddesiyle değiştirilen 17’nci maddesinin birinci fıkrasında, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107’nci maddesine yapılan yollamanın, bu maddenin dördüncü fıkrasıyla sınırlandırılmasına yönelik değişiklik yapılmıştır. Böylece, örgüt mensubu suçlu olmasalar bile, Terörle Mücadele Kanununun örneğin 6’ncı maddesi ile 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan suçların failleri hakkında da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107’nci maddesinin örgüt mensubu suçlulara ilişkin koşullu salıverilme ve hatta, mükerrirlere özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Dikkat edilmelidir ki, **terörizmin finansmanı** suçu 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının önlenmesi Hakkında Kanunda (m. 4) tanımlanmış olmakla birlikte, bu suçtan dolayı mahkum olunan hapis cezasının infazında 3713 s. TMK'nin infaza ilişkin hükümleri uygulanacağı için (6415 s. K, m. 4, f. 6), mahkum olunan cezanın **dörtte üçü** “infaz kurumunda” iyi halli olarak çekildiği takdirde koşullu salıvermeden yararlanılabilecektir.

Ancak belirtmek gerekir ki,

a) **Terörle Mücadele Kanunu** kapsamına giren suçların,

b) **Cinsel saldırı** (TCK, m. 102), **Çocukların cinsel istismarı** (TCK, m. 103), **Reşit olmayanla cinsel ilişki** (TCK, m. 104)¹⁸⁹ ve **Cinsel taciz** (TCK, m. 105) suçlarının,

c) **Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti** suçunun (TCK, m. 188),

failinin **çocuk** olması halinde, bu suçlardan dolayı mahkum olduğu cezanın **üçte ikisini** “infaz kurumunda” çektiği takdirde koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir (İnfaz K, m. 107, f. 2).

Bu grupta yer alan istisnai suçlardan birini işlemekten dolayı mahkum olunan,

“a) *Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,*

b) *Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,*”

“infaz kurumunda” iyi halli olarak çekilmesi halinde, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir (İnfaz K, m. 108, f. 9 yollamasıyla f. 1; keza 3713 s. TMK, m. 17, f. 1 yollamasıyla İnfaz K, m. 108, f. 1).

Örneğin terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen **kasten öldürme** (TCK, m. 81, 82, 83), **orman yakma** (6831 s. Orman K, m. 110, f. 5) suçundan dolayı mahkum edilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının **otuz dokuz yılı**

Bu istisnai hal dışında, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107'nci maddesindeki koşullu salıverilmeye ilişkin diğer genel hükümlerin 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak da uygulanacağına kuşku yoktur.” (Gerekçe metni için bkz. TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Sıra Sayısı: 1222.

¹⁸⁹ Bu hüküm, her ikisi de on beş yaşını tamamlamış çocukların birbirleriyle olan karşılıklı rızaya dayalı cinsel ilişkiye girmeleri halinde de TCK, m. 104, f. 1'de tanımlanan Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluştuğunu ve bu durumda suçun failinin erkek olduğunu kabul eden hukuk dışı anlayışın yansımaları olarak kanun metnine girmiştir. Bu anlayışın eleştirisi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Cinsel Suçlar, Türk Ceza Kanununun Cinsel Suçlara İlişkin Düzenlemelerinin Dayandığı Felsefi Temel, Cinsel Suçlara İlişkin Kanun Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlar*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXIV, sayı 1, Ocak 2020, sh. 267; aynı yazar: *Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bakımından İlgilinin Rızasının Ceza Hukuku Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXIV, sayı 2, Nisan 2020, sh. 263; KOCA, Mahmut/BOZKURT, Özge/AKAR, İbrahim: *Çocukların Kendi aralarındaki Cinsel İlişkinin Cezalandırılabilirliği Sorumu*, in: Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan, Ankara, 2020, sh. 633 vd.

nın, müebbet hapis cezasının ise **otuz üç yılının** “infaz kurumunda” iyi halli olarak çekildiği takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir.

Keza, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen örneğin **kasten yaralama** (TCK, m. 86, 87), **kişiyi hürriyetinden yoksun kılma** (TCK, m. 109), **yağma** (TCK, m. 148, 149), **mala zarar verme** (TCK, m. 151, 152), **ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması** (TCK, m. 223), **bilişim sistemine girme** (TCK, m. 243), **sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme** (TCK, m. 244), **kaçmaya imkan sağlama** (TCK, m. 294), **kaçakçılık** (5607 s. KMK, m. 3) suçundan dolayı mahkum edilmiş olan süreli hapis cezasının **dörtte üçü** “infaz kurumunda” iyi halli olarak çekildiği takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir (3713 s. TMK, m. 4).

III. Ceza hukukunun temel kurallarından birisi, “*kaç fil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır*” şeklinde ifade edilmektedir. Bunun istisnaları, suçların içtimai bölümünde belirlenmiştir (m. 42-44). Bu istisnalar dışında, işlenen **her bir suçla ilgili olarak** ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir. Böylece **verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır**. Hükmolunan birden fazla cezanın ne suretle infaz edileceği sorununun İnfaz Kanununda düzenlenmesi gerektiği düşüncesiyle; **yeni TCK’da “cezaların içtimai”na ilişkin hükümlere yer verilmiştir**. Her bir ceza bağımsızlığını muhafaza etmekle birlikte, bu cezaların infazı bakımından koşullu salıverilme imkanının da varlığı gereklidir. **Ne kadar süreyle hapis cezasına mahkum edilmiş olursa olsun, infaz kurumunda cezasını çekmekte olan hükümlünün yine de koşullu salıverilmeden yararlanabilme, şartları ağır da olsa, toplumsal ortama tekrar geri dönmeye ilişkin ümitlerinin canlı tutulması gerekir**. Aksi takdirde, suçlunun cezalandırılmasıyla güdülen amaca aykırı davranılmış olur. Keza, infaz kurumunda cezasını çekmekte olan ve toplumsal ortama tekrar geri dönme ümidi bulunmayan hükümlünün bir suç makinesine dönüşmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkar. İnfaz kurumunda uygulanan iyileştirici eğitim programlarından beklenen faydanın bu hükümlülerle ilgili olarak sağlanması tamamen hayalden ibaret kalır. Bu düşüncelerle, İnfaz Kanununda, ne kadar süreyle hapis cezasına mahkum edilmiş olursa olsun, infaz kurumunda cezasını çekmekte olan hükümlünün yine de koşullu salıverilmeden yararlanabilmesine imkan tanıyan bir düzenleme yapılmıştır:

“Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;

- a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı,*
- b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz,*
- c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı,*

- d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz,
 e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmisekiz, yıldır.” (İnfaz K, m. 107, f. 3).

Keza, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyeti çerçevesinde işenmiş olan suçlardan dolayı,

- “a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kırk,
 b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzdört,
 c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla kırk,
 d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzdört,
 e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki,

yıl”ın infaz kurumunda iyi halli olarak geçirilmesi halinde, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir (İnfaz K, m. 107, f. 4). Ancak, bu suçların failinin ve sair suç ortağının çocuk olması halinde İnfaz K, m. 107, f. 3’deki azami süreler dikkale alınır (İnfaz K, m. 107, f. 4, son cümle).

IV. İnfaz Kanununun sisteminde çok sayıda suçtan dolayı birden fazla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bir suçun cezası çekildikten sonra, sırasıyla diğer suçların cezaları birbiri ardınca çekilecektir.

Örnek 1. Kişi, kapı kırarak girdiği konutta hırsızlık suçu işlemekten dolayı mahkûm edilir. Bu durumda kişi, işlediği mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından dolayı mahkûm olduğu cezaları birbiri ardına çekecektir. Buna göre, önce mala zarar verme suçunun cezası infaz edilecektir. Bu suçun cezasının infazından dolayı koşullu salıverildiği takdirde, koşullu salıverilme tarihi itibarıyla ikinci suç olan konut dokunulmazlığının ihlali suçunun cezasının infazına başlanacaktır. Bu ikinci suçun cezasının infazı sürecinde koşullu salıverildiği takdirde de, bu koşullu salıverilme tarihi itibarıyla üçüncü suç olan hırsızlık suçunun cezasının infazına başlanacaktır. Ancak bu suretle art arda infaz edilen cezaların infazı sürecinde infaz kurumunda geçirilmesi gereken azami süreler (İnfaz K, m. 107, f. 3, 4) aşılamaz.

Örnek 2. A, B’ye karşı kasten yaralama ve hakaret suçlarını işler. Bu iki suçtan dolayı A hakkında iki ayrı mahkûmiyet hükmü kurulur. Bu durumda, önce kasten yaralama suçunun cezasının infazından başlanır. Bu suçun cezasının infazı sürecinde A’nın koşullu salıvermeden yararlanması halinde, koşullu salıvermeden yararlandığı tarih itibarıyla ikinci suç olan hakaret suçunun cezasının infazına başlanır.

Örnek 3. A, silahla ateş ederek B ve C'yi yaralar. A hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten veya kasten yaralama suçundan dolayı iki ayrı mahkûmiyet hükmü kurulur. Bu durumda önce B'ye karşı işlediği suçtan dolayı mahkûm olduğu ceza infaz edilir. Bu suçun cezasının infazı sürecinde A'nın koşullu salıvermeden yararlanması halinde, C'ye karşı işlediği suçun cezasının infazına bu koşullu salıverme tarihi itibarıyla başlanır.

Örnek 4. A, yağma suçu işler. Bu suçtan dolayı mahkûm olduğu 12 yıl hapis cezasının infazı sürecinde koşullu salıverilmeden yararlanır; ancak denetim süresi zarfında (koşullu salıverildikten bir yıl sonra) hırsızlık suçu işler ve bu suçtan dolayı hakkında ikinci bir mahkûmiyet hükmü kurulur. Hırsızlık suçundan dolayı verilen mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi halinde, yağma suçundan dolayı verilen cezanın infazı sürecinde verilen koşullu salıverilme kararı geri alınır.

7242 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre, (İnfaz K. m. 107, f. 2), A, yağma suçundan dolayı mahkûm olduğu cezanın infazına başladıktan itibaren **6 yıl** geçtikten sonra koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir. Yukarıdaki örnekte A, hırsızlık suçunu, yağma suçundan mahkûm olduğu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverildikten bir yıl sonra işlemiştir. Bu durumda, A hakkında hırsızlık suçundan dolayı verilen mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi üzerine, yağma suçunun cezasının infazı sürecinde verilen koşullu salıverilme kararı geri alınır. Bunun üzerine, A'nın yağma suçundan mahkûm olduğu cezanın infaz kurumunda çektirilmesine yeniden başlanır ve **5 yıl** daha ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra bihakkın tahliye edilir (İnfaz K. m. 107, f. 13, bent a). Yağma suçunun cezasının infazı sürecinde bihakkın tahliye tarihi itibarıyla da hırsızlık suçunun cezasının infazına başlanır.

7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu bağlamda ilave bir hükme yer verilmiştir. Yukarıdaki örneğimizde, A, yağma suçunun cezasının infazı sürecinde koşullu salıverildikten bir yıl sonra işlediği hırsızlık suçundan dolayı **1 yıl** hapis cezasına mahkûm edilmiş olsun. Bu durumda, işlediği yağma suçundan dolayı mahkûm olduğu cezanın infazı sürecinde verilen koşullu salıverilme kararı geri alındıktan sonra, A bu suçun cezasını infaz kurumunda çekmeye devam edecektir. Ancak bu durumda A'nın ceza infaz kurumunda çekeceği ceza, (hırsızlık suçundan dolayı mahkûm olduğu cezanın iki katı olan) **2 yıl** olacaktır (İnfaz K. m. 107, f. 13, bent a). Bu cezanın bihakkın çekilmesi üzerine hırsızlık suçunun cezasının infazına başlanacaktır¹⁹⁰.

¹⁹⁰ **7242 sayılı Kanunla yapılan değişikliktten önceki** düzenlemeye (İnfaz K. m. 107, f. 13, bent a) göre, A, yağma suçundan kalan cezasını hırsızlık suçunu işlediği tarihten itibaren aynen çekecektir. Yağma suçunun cezasının infazı sürecinde bihakkın tahliye tarihi itibarıyla da hırsızlık suçunun cezasının infazına başlanacaktır.

Şöyle ki, yağma suçundan dolayı hakkında 12 yıl hapis cezasına hükmedilmiş olan A, bu cezasının infazına başladıktan itibaren **8 yıl** geçtikten sonra (7242 s. Kanunla yapılan değişikliktten önceki İnfaz K. m. 107, f. 2), koşullu salıverilmeden yararlanarak serbest bırakılır; ancak, koşullu salıverildikten bir yıl sonra hırsızlık suçunu işler. Bu hırsızlık suçundan dolayı verilen örneğin

Sonuç itibarıyla belirtmeliyiz ki, İnfaz Kanununun bu sisteminde mahkum olunan **birden fazla hapis cezasının toplanarak infazı mümkün değildir**. 7242 s. Kanunla mahkumiyetin sebebini oluşturan suça göre belirlenen koşullu salıverilme süreleri karşısında cezaların toplanarak infazının mümkün olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

V. 765 sayılı TCK'nın sisteminden farklı olarak, yeni TCK'nın sisteminde, tekrerrür, cezanın artırılmasını gerektiren bir neden olarak kabul edilmemiştir. Tekerrür halinde suç işleyen kişi, itiyadî suçlu, suçu meslek edinen kişi ve örgüt mensubu suçlu gibi, toplum açısından daha fazla tehlike ifade etmektedir. Bu itibarla, mükerrerlerin de koşullu salıverilmeden yararlandırılabilmesi için, diğer suçlulara nazaran daha fazla süreyle infaz kurumunda kalmaları kabul edilmiştir:

“Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,

c) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki yılının,

*c) Süreli hapis cezasının **üçte ikisinin,***

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.” (İnfaz K, m. 108, f. 1).

Ancak, mükerrir olmayı gerektiren ikinci suçun yukarıda II. No'lu paragraf altında sayılan suçlardan olması halinde, bu suçtan dolayı mahkum olunan **süreli hapis cezasının dörtte üçü** “infaz kurumunda” iyi halli olarak çekildiği takdirde koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir (İnfaz K, m. 108, f. 1, ikinci cümle).

Buna karşılık, *“tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekrerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.”* (İnfaz K, m. 108, f. 2).

“İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.” (İnfaz K, m. 108, f. 3).

İşaret etmek gerekir ki, Yeni TCK'ya göre, *“mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadî suçlu, suçlu*

4 yıl hapis cezasına mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi üzerine, yağma suçundan dolayı verilen koşullu salıverilme kararı geri alınır. Bu durumda, A hakkında yağma suçundan dolayı verilen cezanın infaz kurumunda çektilmesine hırsızlık suçunu işlediği tarih itibarıyla yeniden başlanır ve kalan ceza aynen çektilir. Başka bir ifadeyle, A hırsızlık suçunu koşullu salıverildikten bir yıl sonra işlediği için, koşullu salıverilme kararının geri alınması üzerine infaz kurumunda çekmesi gereken süre **3 yıl** olacaktır. Bu üç yıllık sürenin bitim tarihi itibarıyla da hırsızlık suçundan dolayı mahkûm olduğu cezanın infazına başlanacaktır. Bu ikinci suç bakımından A hakkında tekrerrür hükümlerinin uygulanması gerekir. Bu itibarla A, hırsızlık suçunun cezasının infazına başlandıktan itibaren 3 yıl geçtikten sonra koşullu salıverilebilecektir.

meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.” (m. 58, f. 9). Bu itibarla, *itiyadî suçlunun*¹⁹¹ veya *suçu meslek edinen kişinin*¹⁹² koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için, daha fazla süreyle ceza infaz kurumunda kalması gerekmektedir. Buna karşılık, İnfaz Kanununda *örgüt mensubu suçlu*¹⁹³ açısından ayrı bir koşullu salıverilme hükmüne yer verildiği için (İnfaz K, m. 107, f. 4); Kanunun koşullu salıverilme dışındaki mükerrirlere özgü infaz rejimine ilişkin hükümlerinin örgüt mensubu suçlular açısından uygulanabileceğini kabul etmek gerekir¹⁹⁴.

VI. İnfaz Kanununda 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla yapılan değişikliği göre, çocuğa karşı işlenen bir suçtan dolayı,

a) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın otuzdokuz yılının,

b) müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde ise, bu cezanın otuzüç yılının,

infaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir (İnfaz K, m. 108, f. 8).

Dikkat edilmelidir ki, koşullu salıverilme sürelerini uzatan bu hükümde, işlenen suç ve suçu işleyen kişinin kişilik durumu değil, mağdurun vasfı ve hükmolunan cezanın miktarı göz önünde bulundurulmuştur. Bu hüküm bakımından önemli olan, kim tarafından ve hangi suç işlenmiş olursa olsun, işlenen suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûm olma. Bu cezalar, somut olayda hükmolunmuş olan sonuç cezalarıdır. Bu hükme göre çocuğa karşı işlenmiş olan bir suçtan ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde çok daha uzun süre infaz kurumunda kalınması gerekmekte iken; çocuğa karşı işlenmiş olan aynı suçtan dolayı çeşitli sebeplerle süreli hapis cezasına mahkûmiyet halinde ise, mahkûmiyetin sebebini oluşturan suç dikkate alınarak, mahkûm olunan cezanın sadece yarısını veya üçte ikisini infaz kurumunda çektikten sonra koşullu salıverilmeden yararlanmak mümkün olacaktır. Kanımızca, **suçu işleyen kişinin kişilik özellikleri ve işlenen suçun mahiyeti göz ardı edilerek, sadece mağdur ve hükmolunan cezanın miktarı göz önünde bulundurularak, bir infaz müessesesi olan ko-**

¹⁹¹ “İtiyadî suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,... anlaşılır.” (m. 6, f. 1, bent h).

¹⁹² “Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,... anlaşılır.” (m. 6, f. 1, bent i).

¹⁹³ “Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi,... anlaşılır.” (m. 6, f. 1, bent i).

¹⁹⁴ Bu konuda ayrıntılı bilgi için, 58'inci madde altında yapmış bulunduğumuz açıklamalara bakılmalıdır.

şullu salıvermenin koşullarının ağırlaştırılması, Anayasa ile güvence altına alınan hukuk önündeki eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

VII. “*Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün onbeş yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.*” (İnfaz K, m. 107, f. 5).

Keza, yukarıda da belirtildiği gibi, İnfaz Kanununun 107. maddesinde 22.7.2010 tarihli ve 6008 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, örgüt mensubu suçluların koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için infaz kurumunda çekmeleri gereken asgari süreyi artıran dördüncü fıkra hükümleri çocuklar bakımından uygulanamayacaktır.

VIII. Türk ceza hukuku sistemi, alelittlak **örgüt üyeliğinden** cezalandırılmaya müsait düzenleme içermemektedir. Türk ceza hukuku sisteminde, örgüt üyesi olmak dolayısıyla mahkumiyet için, kişinin;

a) örgütün faaliyeti çerçevesinde veya örgütün korkutucu gücünden yararlanarak (“örgüt adına”) bir **suç işlemesi**,

ya da,

b) örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bu özelliğini bilerek ve isteyerek yardım etmesi,

gerekmektedir.

TCK ve TMK düzenlemeleri, bu fiiller olmadan örgüt üyeliğinden mahkumiye-te asla izin vermemektedir. Bu nedenledir ki, İnfaz Kanununda, örgüt üyeliğinden mahkumiyet haline özgü olarak koşullu salıverilme için infaz kurumunda çekilmesi gereken süre bakımından bir hükme yer verilmemiştir (m. 107, f. 4). Bu, bilinçli bir tercihtir¹⁹⁵.

IX. Mahkûm olduğu hapis cezasının süresi ne olursa olsun, hükümlü kural olarak koşullu salıverilmeden yararlanabilmelidir. Ancak, İnfaz Kanununda bunun **istisnalarına** yer verilmiştir:

a) Hükmolunan belirli sürelerle kadarki hapis cezalarının İnfaz Kanununda öngörülen **özel infaz usullerinden** (m. 110) birine göre çektirilmesi halinde, bu cezanın infazı açısından artık koşullu salıverilme hükümleri uygulanmazdı. Ancak, 7242 s. Kanunla yapılan değişikliğe göre, hapis cezasının özel infaz usullerinden birine göre infaz edilmesi halinde de koşullu salıverilme hükümleri uygulanabilecektir (İnfaz K, m. 110, f. 5).

b) “5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Bölüm, “Anayasal Düzene ve Bu

¹⁹⁵ ÖZGENÇ, Suç Örgütleri, 13. bası, sh. 25.

Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı Beşinci Bölüm, "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz." (İnfaz K, m. 107, f. 16)^{196, 197}.

¹⁹⁶ Yeni İnfaz Kanununun 107'nci maddesinin onaltıncı fıkrasındaki bu hükme paralel olarak Kanunun Geçici 2'nci maddesinde, şu hükme yer verilmiştir:

"14.7.2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun 1'inci maddesi ile değişik 3.8.2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla; ölüm cezaları, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası, hayatı boyunca devam eder."

Benzer bir hüküm, 14.07.2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunla Terörle Mücadele Kanununun 17. maddesine bir fıkra olarak eklenmişti. Ancak, İnfaz Kanunundaki düzenlemeler karşısında yürürlükten kaldırılması gereken bu fıkra hükmü, "korkulu rüya görmektense, uyanık yatmak daha evladdır" mantığıyla, metninde bazı değişiklikler yapılarak aynen muhafaza edilmiştir:

"Ölüm cezaları, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun 1'inci maddesi ile değişik 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder."

Terörle Mücadele Kanununda daha sonra 29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 17. maddeye dördüncü fıkra olarak konulan yeni hükümle **korkulu rüya görme sendromunun** hala devam ettiğini üzümler ifade etmem gerekmektedir. Ancak, özellikle hükümlü **Abdullah Öcalan**'ın durumu dikkate alınarak muhtelif kanunlara konulmuş olan bu hükmün, yanlış olacağı ve bir fayda sağlamayacağı, bu konuda karar verme mevkiinde bulunan mercilere tarafımızdan ifade edilmesine rağmen, düzenleme bu yönde yapılmıştır. Nitekim, hükümlü Abdullah Öcalan'ın vekaletini üstlenen avukatlar aracılığıyla **Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine** yapılan başvuru üzerine, Mahkeme, bu düzenlemelerle Türkiye'nin AIHS'nin 3. maddesi hükmünü ihlal ettiği yönünde karar vermiştir (18 Mart 2013 tarihli Öcalan/Türkiye Kararı). Bu karar üzerine, gerek 5275 s. İnfaz Kanununun Geçici 2. maddesinin yürürlükten kaldırılması, 107. maddesinin onaltıncı fıkrası ile Terörle Mücadele Kanununun 17. maddesinin dördüncü fıkrasının en azından değişikliğe tabi tutulması gerekmektedir.

¹⁹⁷ Bu düzenlemeler, **millîterarası ceza hukuku** uygulamasında da Türkiye'nin başına sorunlar açmaktadır:

Bingöl Valisine 5 Nisan 1999 tarihinde **bombalı saldırı** düzenlenir. Vali yara almadan kurtulur ise de, bu saldırı sebebiyle olay yerinde bulunan 13 yaşında bir çocuk ölür ve 12 kişi yaralanır. Saldırıyı düzenleyen kişi de, üzerindeki bombanın patlaması sonucu parçalanarak ölür.

Bu olayda, saldırganın fırlattığı ve Valinin ayaklarının dibine düşen üç el bombası patlamaz; fakat Valinin aracına doğru fırlatılan bombalar patlar ve makam aracında hasara yol açar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan **X** hakkında bu olayın **azmettiricisi** olduğu ve bununla bağlantılı olarak diğer bazı suçları işlediği iddiasıyla kamu davası açılır. Ancak **X** bu arada Almanya'ya kaçır. Türkiye'de yargılanmasını sağlayabilmek için **X**'in Almanya'dan iadesi talep edilir.

Hamm Eyalet Yüksek Mahkemesi, **X**'in Türkiye'ye iade edilebilirliği konusunda herhangi bir hukuki engel görmez, yani **X**'in Türkiye'ye iadesi yönündeki talebin **kabul edilebilir** olduğu-na karar verir.

Tekrar belirtmek gerekir ki; **ne kadar süreyle hapis cezasına mahkum edilmiş olursa olsun**, infaz kurumunda cezasını çekmekte olan hükümlünün yine de koşullu salıverilmeden yararlanabilme, şartları ağır da olsa, toplumsal ortama tekrar geri dönmeye ilişkin ümitlerinin canlı tutulması gerekir. Bu nedenle, kanaatimizce bu hükümler doğru olmamıştır. Belirli suçlardan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olup da cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlüler hakkında koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmaması, artık bir daha gün ışığına çıkma yönündeki ümitleri tükenmiş olan bu hükümlülerin bir eğitim programına tabi tutulmasını gereksiz kılmaktadır. Bu hükümlüler bir eğitim programına tabi tutulsa bile, uygulanacak olan program başarısız kalacaktır¹⁹⁸.

X, bu karara karşı “Anayasa şikayeti” (bireysel başvuru) hakkını kullanarak Federal Anayasa Mahkemesine başvurur.

X, bu başvurusunda, Türkiye’ye iade edildiği takdirde **ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası** ile cezalandırılabileceğini, kendisine yüklenen suçların arasında terör örgütü yöneticisi olmak (TCK, m. 314, f. 1) ve özellikle “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” (TCK, m. 302) suçlarının bulunması sebebiyle, bu cezaya mahkum edilmesi halinde, **koşullu salıverilmeden yararlanamayacağını** ve bu durumun bir **iade engeli** olduğunu ileri sürmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Cumhurbaşkanının sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaı hafifletmek veya kaldırmak yetkisinin düzenleme itibarıyla varlığına rağmen, bu durum, X’in bu imkandan yararlanması bakımından bir hak oluşturmamaktadır. Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, bu durumu bir **temel hak ihlali** olarak değerlendirmiştir.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi’ne göre, mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi ne kadar uzun olursa olsun, kişiye tekrar topluma geri dönme imkanı tanınmalıdır. Hükümlüde bu ümidin canlı tutulabilmesi bir şekilde güvence altına alınmalıdır. Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın af yetkisinin düzenlenmiş olması, bunun için yeterli değildir. İade talep eden devlet hukukunda, mahkum edilen cezanın infazı sürecinde hükümlüye tekrar topluma geri dönme, özgürlüğüne yeniden kavuşma imkanı verildiği, hakkı tanındığı takdirde, bu talep kabul edilebilmelidir. Mahkum olunan hürriyeti bağlayıcı cezanın ömür boyu devam etmesi “acımasız ve aşağılayıcıdır”.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, bu şartlar altında X’in Türkiye’ye iadesi yönündeki talebin kabul edilmesini Alman Anayasasına uygun bulmamıştır (BVerfG, 16.1.2010, 2 BvR 2299/09).

¹⁹⁸ Ancak, işaret etmek gerekir ki; Anayasa Mahkemesine göre, “*Yasakoyucu, şartla salıverilmenin koşullarını, örneğin, yararlanma sürelerini, kimi suçlardan mahkûmların bundan yararlanıp yararlanamayacaklarını, ya da farklı biçimde yararlanabileceklerini, zaman içerisinde toplumun gelişmesine göre, serbestçe takdir edilebilecektir.*” Bu itibarla, bazı suçların faillerinin koşullu salıverilmeden yararlanamaması, **mahkum olunan hürriyeti bağlayıcı cezaya göre koşullu salıverilmeden yararlanma şartlarının farklılık arz etmesi, Anayasaya aykırı değildir**: Anayasa Mahkemesi’nin 19.7.1990 tarihli ve Esas: 1989/35, Karar: 1990/22 sayılı Kararı (RG: 21 Mart 1991/20821, sh. 17 vd.).

Anayasa Mahkemesi, Terörle Mücadele Kanununun, kapsamına giren suçlarla ilgili özel koşullu salıverilme hükümlerini içeren 17. maddesinin iptali talebini aynı gerekçelerle reddetmiştir (31.3.1992 tarihli ve E. 1991/18, K. 1992/20 sayılı Karar):

“*Yasa’nın 17. maddesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar için şartla salıverilme koşulları özel olarak düzenlenmiştir.*

Yasakoyucu, şartla salıverilmenin koşullarını, örneğin yararlanma sürelerini, kimi suçlardan mahkûmların bundan yararlanıp yararlanmayacaklarını, ya da ne şekilde yararlanabileceklerini zaman içerisinde toplumun gelişmesine göre, takdir edebilir. Terörle Mücadele Yasası kapsamı-

- c) Yukarıda da belirttiğimiz gibi, “*ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.*” (İnfaz K, m. 108, f. 3).
- d) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı **Bankacılık Kanununun** 168’inci maddesine göre, bu Kanunda tanımlanan özel nitelikteki zimmet suçundan “... *dolayı*

na giren suçlar ile diğer suçlar arasındaki ayrılık doğal olarak bunlara ilişkin cezaların yerine getirilmesinde de farklılıklar yaratabilir. Bunun ölçülerini toplumsal gereksinimler gösterir.

Değişik eylemler için değişik yaptırımlar öngörebilmesi yasakoyucunun takdir alanına girdiği gibi şartla salıverme yönünden de kimi suçlar için ayrı kurallar konulması eşitlik ilkesine aykırı değildir.

Yasakoyucu, toplumun huzuru ve suçların önlenmesi açısından, terör suçlarını işleyenlerin, cezalarının, daha uzunca bir bölümünü çektikten sonra şartla salıverilmelerinin yararlı olacağı kanısıyla böyle bir düzenleme yapmayı uygun bulmuştur.

Yukarıda yazılı nedenlerle madde Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı değildir.” (RG: 27 Ocak 1993/21478 Mükerrer, sh. 65).

765 s. (mülga) “*Türk Ceza Yasası’nın 125. maddesinde belirtilen suçları işleyenlerin daha uzun süre cezaevinde tutularak şartla tahliyesini öngören dava konusu kuralda yasakoyucuyu farklı düzenleme yapmaya iten haklı neden vardır. Hükümlünün şartla salıvermeden yararlanabilmesi için gerekli olan iyi durumlu olma ve cezaevi kurallarına uyma koşulları, maddede belirtilen suçları işleyenler için aranmamıştır. Toplum düzeni ve kamu yararı gözetilerek suç türüne göre ayırım yapılmış ve bazı hükümlülerin şartla salıverilmesi için cezaevinde geçirecekleri süre daha uzun tutulmuştur. Belirtilen nedenlerle iptal isteminin reddi gerekir.*” (RG: 27 Ocak 1993/21478 Mükerrer, sh. 71).

Fakat, Anayasa Mahkemesinin farklı yönde kararları da mevcuttur:

“... *cezanın infazı, işlenen suçun türüne bağlı olmaksızın, suçlunun topluma uyum sağlamasını ve topluma yeniden kazandırılmasını amaçlar.*

Bu amacın gerçekleştirilebilmesi, suça bağlı kalmadan ayrı bir programın uygulanmasını gerektirir. Tüm çabalar, suçlunun uyumsuzluğuna neden olan psikolojik, çevresel, sosyal ve kişisel etkenlerin belirli bir infaz programı içinde giderilerek, suça yeniden yönelmesini önlemektir. Bu program, suça göre değil, suçlunun infaz süresince gösterdiği davranışlarına ve gözlenen iyi durumuna göre düzenlenecektir. Bu da infazın, mahkûmların işledikleri suçlara göre bir ayırıma gidilmeden, aynı esaslara ve belirli bir programa göre yapılmasını ve sonuçlarının gözlenmesini gerektirir. Aynı miktar cezayı alan iki hükümlüden birinin, sırf suçunun türü nedeniyle daha uzun süre ceza çektikten sonra şartla salıverilmesi, cezaların farklı çektilmesi sonucunu doğurur ve bu iki mahkûm arasında eşitsizliğe neden olur.

Şartla salıvermede çağdaş eğilim, özgürlüğü bağlayıcı cezanın yasalarla belirlenecek bir alt sınırının infaz kurumunda geçirilmesi koşuluyla, suçlunun kişiliğindeki gelişmeleri gözleyerek uygun zamanın belirlenmesi yönündendir. Bu yöntemde işlenen suçun, şartla salıverme açısından belirleyici bir niteliği yoktur.

Böylece, infaz yönünden eşit ve aynı durumda bulunan mahkûmlar arasında şartlı salıverme bakımından ayrı uygulama, Anayasa’nın 10. maddesinde öngörülen yasa önünde eşitlik ilkesine uygun düşmemekte ve bu ayrılığın haklı bir nedeni de bulunmamaktadır.”: Anayasa Mahkemesi’nin;

a) 19.7.1991 tarihli ve Esas: 1991/15, Karar: 1991/22 sayılı Kararı (RG: 31 Temmuz 1991/20946, sh. 37 vd.);

b) 19.7.1991 tarihli ve Esas: 1991/17, Karar: 1991/23 sayılı Kararı (RG: 7 Ağustos 1991/20953, sh. 21 vd.);

c) 19.7.1991 tarihli ve Esas: 1991/19, Karar: 1991/24 sayılı Kararı (RG: 7 Ağustos 1991/20953, sh. 31 vd.);

d) 19.7.1991 tarihli ve Esas: 1991/22, Karar: 1991/25 sayılı Kararı (RG: 7 Ağustos 1991/20953, sh. 40 vd.).

mahkûm olanlar, Fona veya Hazineye olan borçları ve tazminatları ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar mal varlıklarından tahsil olunamadığı sürece, bunlar hakkında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.”

İşaret etmemiz gerekir ki, yeni Bankacılık Kanununun bu hükmü ceza hukuku ilke-leriyle bağdaşmamaktadır. Bir ceza infaz kurumu olan koşullu salıverilmeden yararlanabilmenin, özel hukuk hükümlerine göre tahsil edilmesi gereken bir alacağın tahsiline bağlı kılınması; cezalandırmakla güdülen amaçla bağdaşmamaktadır.

2) Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Koşullar

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için, “*mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir*” (İnfaz K, m. 107, f. 1). Bu itibarla, **iyi hal**, koşullu salıverilme kurumunun esaslı unsurunu oluşturmaktadır. Mahkûmun infaz kurumundaki iyi hali, serbest bırakıldığında bir daha suç işlemeyeceği konusunda bir emare teşkil etmektedir. İyi halin tespiti açısından, kişinin işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyup duymadığı, dışarı çıktığında tekrar suç işleme eğilimi gösterip göstermediği hususları araştırılmalıdır¹⁹⁹.

İnfaz Kanununun “*Hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi hâlin belirlenmesi*” başlıklı 89'uncu maddesine göre;

“(1) Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hâlin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim-öğretim programları ile spor ve sosyal faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınır.

(3) Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz

¹⁹⁹ SOYASLAN, Doğan. *Şartlı Tahliye*, in: Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989, sh. 522.

kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı başkanlık eder. Ayrıca, idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer uzman kişi katılır.

...

(5) Kanunlarda iyi halliliğin arandığı durumlarda, hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi bakımından bu madde hükümleri uygulanır.

(6) Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin olarak tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tâbi tutulma süreleri bir yılı geçemez.

(7) İdare ve gözlem kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelere esas olacak ilkeler ve kurulun bu maddeye ilişkin çalışma usul ve esasları ile tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tâbi tutulma süreleri yönetmelikle düzenlenir.”

Terörle Mücadele Kanununda iyi halliliğin tespitiyle ilgili olarak ek bir hükme yer verilmiştir:

“Tutuklu veya hükümlü iken firar veya ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş bulunanlar ile disiplin cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıverilmeden yararlanamazlar.” (3713 s. TMK, m. 17, f. 2).

Belirtilen durumlarda terör suçlusu iyi halli olarak kabul edilmeyecek ve dolaşısıyla, koşullu salıverilmeden yararlanamayacaktır.

C. Hükümlünün Koşullu Salıverilmeye Hazırlanması

İnfaz Kanununda, hükümlünün serbest hayata uyumunu sağlamaya yönelik olarak, *koşullu salıverilmeden önce alınması gereken tedbirler* belirlenmiştir. Kanunun “Salıverilme öncesi için önlem ve ilişkiler” başlıklı 90’ıncı maddesine göre;

“Hükümlünün salıverildikten sonraki geleceğini düzenlemeyi düşünmesini sağlayıcı tedbirler alınır ve toplumla uyumu ile ailesinin çıkarları için bu konularda hizmet veren resmî ve özel kuruluş veya kişilerle ilişki kurması doğrultusunda katkı ve yardımda bulunulur.”

Keza, Kanunun “Hükümlüye iş bulmada yardım” başlıklı 91’inci maddesine göre;

“Hükümlü, salıverildiğinde iş bulması veya kendi işini kurması yönünde özendirilir. Bu konuda gönüllü kişi ve kuruluşlar ile resmî kurumlarla iş-

birliği yapılır. Bu husustaki ayrıntılar Cumhurbaşkasınca çıkarılan yönetmelikte gösterilir.”

Ayrıca, mahkûmun serbest hayata uyumunu sağlamaya yönelik olarak, koşullu salıverilmeden önce de izinli olarak dışarıya çıkarılması mümkün kılınmıştır:

“Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin verilebilir.” (İnfaz K, m. 96, f. 1).

Bu iznin verilebilmesi için, mahkûmun talepte bulunması gerektiği hususunda Kanunda hüküm bulunmamaktadır. Ancak, bu iznin mahiyeti gereğince, mahkûmun bundan yararlanmayı istemesi gerekmektedir²⁰⁰.

Ancak, işaret etmek gerekir ki, İnfaz Kanununa 5.4.2012 tarihli ve 6291 sayılı Kanunla eklenen “Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı”na ilişkin hükümler (m. 105/A) karşısında, söz konusu Kanunun bu (m. 96) düzenlemesinin bir anlamı kalmamıştır.

D. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi

Hükümlünün koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için, bir karar verilmesi gerekir. Ancak bunun için mahkûmun talepte bulunması gerekmediği gibi, rızası da aranmamaktadır. Yukarıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, bu konuda re’sen karar verilir.

Koşullu salıverilme konusunda karar verme yetkisi, *infaz işlemlerinin yapıldığı yer infaz hakimliğine* aittir (İnfaz K, m. 107, f. 11).

Koşullu salıverilme kararından önce, bu kararın verilmesinde dikkate alınmak üzere, hükümlü “*hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından ... gerekçeli rapor*” hazırlanır. “*İnfaz hâkimi, bu raporu (dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda,) uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir.*” (İnfaz K, m. 107, f. 11).

Ancak, “*İnfaz hâkimi, ... raporu (dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda, koşullu salıverilmesini) uygun bulmadığı takdirde*” hükümlünün cezasını infaz kurumunda çekmesine karar verir ve “*gerekçesini kararında gösterir.*” (İnfaz K, m. 107, f. 11).

“Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.” (İnfaz K, m. 107, f. 11).

İnfaz hakimi, ceza infaz kurumu idaresinin raporu ile bağlı değildir²⁰¹.

²⁰⁰ ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 222.

İnfaz hakimî tarafından hükümlünün koşullu salıverilmesine karar verilmesi halinde, bu karar derhal yerine getirilir ve hükümlü salıverilir.

Ancak, işaret etmek gerekir ki, hükümlü hakkında “*disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi yapılmaz*” (İnfaz K, m. 48, f. 3, bent b).

E. Cezanın Kalan Kısmının Kurum Dışında İnfaz Edilmesi

Koşullu salıverilme kararına istinaden serbest bırakılan mahkûmun **cezasının kalan kısmı** kurum dışında infaz edilecektir. Başka bir ifade ile, koşullu salıverilmeye rağmen mahkûmun cezasının infazına devam edilmektedir. Koşullu salıverilen hükümlü açısından cezasının kalan süresi içinde de mahkûmiyetin gerekli kıldığı bazı hak yoksunlukları (TCK, m. 53) devam etmektedir. Ancak, koşullu salıverilen hükümlü, “*kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayımlık yetkileri*”ni kullanabilecektir (TCK, m. 53, f. 3).

Koşullu salıverilen hükümlünün cezasının infaz kurumunun dışında çekeceği kısmına ilişkin süreye, **denetim süresi** denir” (İnfaz K, m. 107, f. 6). Denetim süresi, kural olarak, mahkum olunan süreli hapis cezasının yarısı kadar, yani infaz kurumunda çekilmesi gereken kısmı kadardır.

Buna göre, örneğin kasten yaralama suçundan dolayı mahkum olduğu 6 yıl hapis cezasının yarısını infaz kurumunda çektikten sonra koşullu salıverilen hükümlü bakımından denetim süresi **3 yıldır**.

²⁰¹ «Mahkûm M.nin, işlediği adam öldürme suçundan dolayı tutuklandığı tarihten başlayarak, üç defa cezaevinden firar etmiş ise de, yakalandığı ve ayrıca görevli gardiyana küfredip sol gözüne yumrukla da vurduğu anlaşılmış; ceza ve tevkif evinden müteaddit defalar kaçmak ve bunlardan başka görevli gardiyana sövüp ayrıca müessir fiil ika etmek suretiyle kanunlara itaatlı ve iyi halli bir kimse olmadığını bizzat ortaya koymuş olan hükümlünün şartla salıverilmesinden faydalanmaya layık bulunmadığı mahkemece takdir edilmiştir. Gardiyana küfredip gözüne yumrukla vurmasından dolayı Adana Ceza ve Tevkif Evi İnzibat Komisyonunca verilmiş olan bir ay hücre cezasının Kırşehir Cezaevi İnzibat Komisyonu tarafından sonradan kaldırılması ve ayrıca hakkında iyi hal kararı verilmesi mahkemeyi bağlamaz.»: 1. CD., 18.12.1965, 2563/2743 (RKD, 1966, sayı 1-12, bölüm III/2, sh. 101 vd.).

«Olayda hükümlü Ü, cezasının 2/3’ünü çekmiş olması hasebiyle şartla salıverilmesi için Kırşehir cezaevi komisyonunun mütalaası o yer ağır ceza mahkemesince tasvip edilmemiş ve bu karara karşı hükümlü tarafından yapılan itirazın da Keskin ağır ceza mahkemesinin kararı ile reddedilmek suretiyle şartla salıvermenin tasvip edilmemesine ait karar kesinleşmiştir. Adı geçen mahkûm Balıkesir cezaevinde bulunduğu sırada üç defa kumar oynarken yakalanmış, her üç defasında da hücre cezasına çarptırılmıştır. Bundan sonra Kayseri cezaevinde iken hakkında düzenlenen raporda iyi ahlâklı bulunmadığı, idareye karşı gelmekte olduğu, zorba ve arkadaşlarıyla geçimsiz olup, cezadan pişmanlık duymadığı belirtilmiş olmasına göre; cezaevinde kaldığı süre zarfında iyi halli olmadığı meydana çıkmıştır. Bu mahkumun sonradan hücre cezasının kaldırılmış olması, iyi halli olduğunu göstermez. Bu itibarla, cezaevi komisyonu tarafından düzenlenen ve mahkûmun cezasının belli bir miktarını iyi halle geçirmiş olduğuna dair olan mütalâa, tatmin edici ve kabule şayan görülmemiştir.»: 1. CD., 24.5.1967, 1271/1340 (RKD, 1967, sayı 1-12, bölüm III/12, sh. 84 vd.).

Ancak, koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkum olunan süreli hapis cezasının asgari olarak üçte iki veya dörtte üç oranında “infaz kurumunda” iyi halli olarak çekilmesi gereken hallerde denetim süresi, “*hakederek tahliye tarihini geçemez.*” (İnfaz K, m. 107, f. 6).

Buna göre, örneğin kasten öldürme suçundan dolayı mahkum olduğu 24 yıl hapis cezasının üçte ikisini infaz kurumunda çektikten sonra koşullu salıverilen hükümlü bakımından denetim süresi **8 yıldır**.

Keza, örneğin terör örgütü yöneticiliği suçundan dolayı yirmi yıl hapis cezasına mahkum edilmiş olan kişi, bu cezanın dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak çektiği takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir. Bu hükümlünün tabi tutulacağı denetim süresi, hak ederek tahliye tarihini geçemeyeceği için, **5 yılla** sınırlı tutulacaktır.

Koşullu salıverilen hükümlü, kural olarak, denetim süresince gözetim ve tretmana (**denetimli serbestlik tedbirine**) tabi tutulur:

“Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılabilir.” (İnfaz K, m. 107, f. 7).

“Onsekiz yaşından küçük olan hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir kurumda devam ederler.” (İnfaz K, m. 107, f. 8).

“İnfaz hâkimi, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek infaz hâkimine verir. İnfaz hâkimi ayrıca, iki yılı geçmemek üzere denetim süresi içinde hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne belirlenecek yükümlülüklerle tabi tutulmasına karar verebilir. Bu karar gereğince denetimli serbestlik müdürlüğü, risk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hükümlüyü;

- a) Belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma,*
- b) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme,*
- c) Belirlenen programlara katılma,*

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutar. Denetimli serbestlik müdürlüğü hükümlünün risk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilir” (İnfaz K, m. 107, f. 9).

“İnfaz hâkimi, koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini ve topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulundurarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya herhangi bir yükümlülük belirlmeden geçirilmesine karar verebileceği gibi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde kaldırabilir.” (İnfaz K, m. 107, f. 10).

Keza, belirtelim ki, İnfaz Kanununun 108. maddesinde 6545 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, TCK’nın,

- a) 102’nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan,
- b) 103’üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan,
- c) 104’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan,

dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında, **cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde**, aşağıdaki **tedavi** veya **yükümlülüklerden bir veya birkaçına** infaz hâkimi tarafından **karar verilir**:

- a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak,
- b) Tedavi amaçlı programlara katılmak,
- c) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak,
- d) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşımdan yasaklanmak,
- e) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak,
- f) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak (İnfaz K, m. 108, f. 9).

Ancak, söz konusu suçların failinin ve sair suç ortağının çocuk olması halinde, çocukla ilgili olarak bu tedbirler uygulanmaz (İnfaz K, m. 108, f. 10).

F. Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi

Koşullu salıverilmeden yararlanan hükümlünün denetim süresini kendisine yüklenen yükümlülüklerle uygun ve iyi hâlli olarak geçirdiği takdirde, **cezası infaz edilmiş sayılır** (İnfaz K, m. 107, f. 14). Denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmiş kabul edilebilmesi için, hükümlünün bu süre zarfında hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlememesi gerekmektedir (İnfaz K, m. 107, f. 12).

G. Denetim Süresi İçinde Yükümlülüklerle Aykırı Hareket Edilmesi veya Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi

*“Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde **hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç** işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklerle, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde **koşullu salıverilme kararı geri alınır.**”* (İnfaz K, m. 107, f. 12).

Buna göre, koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için, denetim süresi içinde **hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç** işlenmesi gerekmektedir²⁰². Buna karşılık,

²⁰² Yürürlükten kaldırılan 765 s TCK ile 647 s. İnfaz Kanununun uygulamasında bu ikinci suçtan dolayı mahkûm olunan cezanın tecil edilmesi halinde şartla salıverme kararının geri alınıp alınmayacağı bir mesele olarak ortaya çıkmıştı. Yargıtay, önce, ertelenmiş cezanın şartla salıverme kararının geri alınmasını gerektirmediği sonucuna varmıştı:

«Mesele, şartla salıverilen mahkûmun deneme sürecinde işlediği bir diğer cürüm nedeniyle verilmiş cezasının 647 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca ertelenmesi durumunda önceden verilen şartla salıverme kararının geri alınmasının mümkün olup olmayacağıdır. TCK'nın 17. maddesi, “şartla salıverilmiş hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur ise şartla salıverilme kararının geri alınacağını” amirdir.

Bu koşullara göre durum değerlendirilmesi yapıldığında; mahkûm H.nın şartla salıverme kararının kaldırılması için yeterli nedenin varlığından söz edebilmek olasıdır. Zira, şartla salıverme ile kendisine tanınan deneme süresinde kasıtlı bir cürüm olan hırsızlığa teşebbüs suçunu işlemiş, bu hal Manisa Asliye Ceza Mahkemesinin kesinleşen mahkûmiyet hükmüyle belgelenmiş ve hürriyeti bağlayıcı cezadan madut beş ay hapse mahkûm olmuştur.

Ancak, ne var ki, Manisa Asliye Ceza Mahkemesi mahkûmun geçmiş ahvalini belgelendirmemiş ve kendisini ilk defa cürüm işleyenlerden kabul ederek beş aylık hapis cezasını 647 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca ertelemiştir.

Hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan veya cezası kesinleşen bir kişinin cezası infaz edilmemiş olsa dahi, sonradan vaki mahkûmiyetinde, erteleme atıfından yararlandırılmasına her ne kadar yasal olanak bulunmamakta ise de, Manisa Asliye Ceza Mahkemesinin işbu erteleme kararı kesinleşmiştir.

Kesinleşmiş bu kararın mahkûm lehine kazanılmış bir hak oluşturduğu ve yasal geçerlilik kazandığı tartışılmaz bir gerçektir. Böyle bir kararı, temelinde yasaya aykırılığın varlığından söz ederek geçersiz saymak ya da ilgilisi yararına sağladığı yarar ve sonuçları kısmen dahi olsa zaafiyete uğratmak olası değildir.

647 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca, ertelenmiş bir mahkûmiyet kararı, TCK'nın 95/2. maddesi koşullarında değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Zikredilen madde hükmüne göre; “Cürüm ile mahkûm olan kimse hüküm tarihinden itibaren beş sene içinde işlediği diğer bir cürümden dolayı evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya, yahut hapis veya ağır hapis cezasına mahkûm olmazsa, cezası tecil edilmiş mahkûmiyeti esasen vaki olmamış sayılacak; aksi halde her iki ceza ayrı ayrı tenfiz olunacaktır. Kanun, mahkûmun iyi hallilik koşuluna bağladığı atıfeti, sadece tecil edilmiş cezanın çektirilmemesi ile sınırlandırmamakta, mahkûmiyet kararını bütünüyle vaki olmamış sayılacağını vaad etmektedir. Bu vaadin mahkûmiyet kararının doğurabileceği her türlü etki ve neticeyi de kapsamına aldığı kuşku yoktur.

Geçmiş mahkûmiyeti bulunan kişinin sonraki cezasının ertelenmesinde yasaya aykırılık olduğuna işaret etmek mümkün ve isabetli ise de; her nasılsa kesinleşmiş bulunan bu hüküm yok sayarak, doğurduğu kazanılmış hakları şu veya bu gerekçe ile daraltmak olanaksızdır.

Artık bu karar, bünyesindeki yasaya aykırılığa rağmen ilgilisi yararına kazanılmış haklar oluşturmakla yasaya uygunluk kazanmış bulunmaktadır. Etki ve bağlayıcı, temelde yasaya uyarlı hükümlerden farklılık arz etmeyecektir.

Bir mahkûmiyet hükmünün, geçmişte verilmiş şartla tahliyenin geri alınmasına dayanak yapılması, o hükmün “sonuç yaratma” özelliğinin sonucudur. Bu hal ancak ve sadece ertelenmemiş mahkûmiyetin varlığıyla olanaklıdır. Ertelenmiş mahkûmiyetlerde ise hükmün yaratabileceği her türlü etkinlik askıya alınmakta ve deneme süresinin sonuna kadar, hükmünün yeni bir cürüm işlememesi koşuluyla geciktirilmekte, süre iyi hallilikle geçirilince mahkûmiyet kararı esasen

vaki olmamış sayılmaktadır. TCK'nın şartla salıverme kararının geri alınma koşullarını hükme bağlayan 17. maddesinde, sonraki mahkûmiyetin varlığından söz edilmiş olmasını yeterli saymak ve ertelenmiş mahkûmiyet halinin istisna olarak gösterilmediğinden söz edilerek konuya çözüm üretmekte isabet görülmemektedir. Bilindiği üzere Yasa koyucu, “olağan”ı öngörerek kural vaz'eder. Olağandışı halleri önceden deriş edebilmek mümkün olmayacağından; bunları sıralayarak önlemlerini kurala bağlamak, Yasa koyucudan beklenmemelidir. Bu nedenledir ki, şartla salıverilmiş bir mahkûmun ertelemeden yararlandırılması biçimindeki olağandışılığa, Kanunun 17. maddesi içeriğiyle sınırlı kalınarak çözüm getirmek olanağı bulunmamaktadır.

İsabetli çözüm, kazanılmış hak oluşturarak yasallık kazanan erteleme kararını tüm sonuçlarıyla geçerli kabul etmek ve erteleme nedenleri ortaya çıkmadıkça şartla salıverme kararını kaldıramayacağını kabul etmektir.»: 1. CD., 5.2.1996, 6/219 (YKD, Mayıs 1996, sh. 797 vd.).

Fakat, bilahare bu görüşünden dönmüştür: «Hükümlü Mustafa, adam öldürme ve yaralama suçlarından içtimaen 15 yıl ağır hapis 4 ay 30 gün hapis cezası ile cezalandırılmış ve bu cezaları kesinleşmiştir. Hükümlü, 25.3.1994 günü şartla salıverilmiş olup bihakkın tahliye tarihi 23.7.2006'dır.

Hükümlü şartla salıverildikten sonra 14.5.1996 günü işlediği 6136 sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan 1 sene hapis ve 300.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmış, 647 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince bu cezası ertelenmiştir.

Deneme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi nedeniyle TCK'nın 17. maddesi uyarınca sanık hakkındaki şartla salıverilme kararının geri alınması talep olunmuş, istemin reddine ilişkin hüküm kesinleşmiştir. Bu hükme yönelik yazılı emirle bozma istemi Özel Dairece reddedilmiş ve bu karara karşı Yargıtay C. Başsavcılığı'na itiraz edilmiştir.

Çözümenecek sorun, şartla salıverilen hükümlünün deneme süresi içinde işlediği bir diğer cürüm nedeniyle verilen cezasının 647 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verilmesi halinde, önceden verilen şartla salıverme kararının geri alınmasının mümkün olup olmadığına ilişkindir.

Şartla tahliye kararı 647 sayılı Yasanın 19 ve şartla salıverme kararının geri alınması ise TCK'nın 17. maddesinde düzenlenmiştir. Şartla salıverilme iyi halliliğe dayanan bir kurumdur. Cezasının bir kısmını iyi halli olarak geçiren bir hükümlünün, cezasının tamamını çekmeden, cezaevinden daha erken salıverilmesidir. Şartla salıverilen hükümlü, iyi halliliğini sürdürmek zorundadır. Aksi halde şartla salıverilme kararı geri alınacaktır. TCK'nın 17. maddesinde “*Şartla salıverilmiş olan hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur veya mecbur olduğu şartları yerine getirmeyen ise, şartla salıverilme kararı geri alınır. Bu takdirde suçun işlendiği tarihten sonraki kısım hükümlünün ceza süresine mahsup edilmeyerek aynen çektilir ve şartla salıverilmeye esas teşkil eden hükmün infazı ile ilgili olarak bir daha şartla salıverilmeden yararlanamaz.*” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre iyi halli olup da şartla salıverilen hükümlü, deneme süresi içerisinde hürriyeti bağlayıcı ceza ile sonuçlanan kasıtlı bir cürüm işlediği ya da uyması gereken koşullara uymadığı takdirde şartla salıverilme kararı geri alınacaktır. Suçun, özgürlüğü bağlayıcı ceza gerektiren kasıtlı bir cürüm olması öngörülmüştür.

Şartla salıverilme kararının geri alınması için hükümlünün, kasdı bir cürümden özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması yeterlidir. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararı, hükümlünün iyi halliliğini yitirdiğini göstermektedir. Bu hükmün kesinleşmiş olması zorunludur. Çünkü, kesin bir mahkûmiyet hükmü olmadan özgürlüğü bağlayıcı cezayı müstelzim kasıtlı bir cürüm işlendiği kabul edilemez. Öte yandan, 8.6.1970 gün 9-4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında “*Şartla salıverilen hükümlülerin meşruten tahliye tarihi ile bihakkın tahliye edilmeleri icabeden tarih arasında şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim kasıtlı bir cürüm işlemeleri halinde TCK'nın 17. maddesi gereğince meşruten tahliye kararının geri alınması gerektiği; ikinci cürümün birinci cürme ait ceza müddeti dolmadan işlenmiş olması yeter olup, cezanın verilip kesinleşmesinin bu süre içinde gerçekleşmiş olmasının şart bulunmadığı*” açıklanmak suretiyle, suçun deneme süresi içinde işlenmesinin yeterli olduğu belirtilmiştir. Şartla

denetim süresi içinde işlenen yeni suç kasten işlenmiş bir suç değilse ya da kasten işlenen bir suç olmakla birlikte, hapis cezasını gerektiren bir suç değilse, yani sadece adli para cezasını gerektiren bir suç ise, koşullu salıverilme kararı geri alınmaz.

Dikkat edilmelidir ki, bu fıkra hükmüne göre; koşullu salıverilme kararının geri alınması için denetim süresi içinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlenmesi gerekmekle birlikte, bu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olmak şart değildir. İşlenen suç hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç olmakla birlikte, somut olayda kişi hakkında hapis cezası yerine seçimlik ceza olarak adli para cezasına hükmedilmiş olabilir. Keza, kişi kasten işlediği suçtan dolayı mahkûm edilmiş olmakla birlikte, hükmolunan kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırım olarak adli para cezasına veya güvenlik tedbirine çevrilmiş olabilir. 765 s. TCK ve 647 s. İnfaz Kanununun düzenlemelerinin aksine, yeni İnfaz Kanununun sisteminde bu gibi durumlarda da koşullu salıverilme kararı geri alınacaktır²⁰³.

salıvermenin geri alınması cürümle ilgili olup, o cürümün cezasının çektirilebilir olmasıyla ilgili bulunmamaktadır. TCK'nın 17. maddesinde, mecbur olunan şartların yerine getirilmemesi halinde şartla salıverilme kararının geri alınması kabul edildiği halde, özgürlüğü bağlayıcı ceza gerektiren bir suçun işlenmesi halinde kararın geri alınamayacağı, ikinci suçun cezasının çektirilebilir olmasının şart olduğu ileri sürülemez. TCK'nın 17. maddesinde "*mahkûm olur*" denmesi, mahkûmiyet kararının yeterli olduğunu, cezanın çekilebilir olmasının nazara alınmadığını göstermektedir. İyi halliliği ortadan kaldıran, cezanın çekilmesi değil, kesinleşmiş mahkûmiyetle sonuçlanan kastî bir cürme ilişkin fiilin varlığıdır.

Deneme süresi içinde işlenen suç nedeniyle hükmolunan cezanın ertelenmesi halinde, yasa koyucunun şartla salıverme kararının geri alınamayacağına dair istisnai bir düzenleme yaptığı söylenemez. Zira, bu durumda kasıtlı suçtan dolayı hükmolunan özgürlüğü bağlayıcı cezanın ertelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır. Bu nedenle ikinci suçtan verilen mahkûmiyet kararının yasaya aykırı olarak ertelenmesi halinde şartla salıverilme kararının geri alınamayacağına ileri sürülmesi, yasa koyucunun amacına aykırıdır.

İncelenen dosyada, adam öldürme ve yaralama suçlarından 15 yıl ağır hapis 4 ay 30 gün hapis cezasına hükümlü Mustafa'nın, bu cezasının infazı sırasında 25.3.1994 tarihinde işlediği şartla salıverildiği, deneme süresi içinde 14.5.1996 tarihinde işlediği izinsiz silâh taşımak suçundan 1 yıl hapis ve 300.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek bu **cezasının ertelendiği** ve hükmün kesinleştiği, bu suretle TCK'nın 17. maddesinde tanımlanan türden bir cürüm işleyip **mahkûm olmakla iyi halliliğini kaybettiği anlaşıldığından, şartla tahliye kararı geri alınmamıştır.**»: CGK., 18.11.1997, 1-156/250 (YKD. Nisan 1998, sh.581 vd.).

Ceza Genel Kurulu'nun bu kararında benimsenen görüş, erteleme bir şartlı atıfet kurumu değil, bir ceza infaz kurumu olarak kabul eden yeni TCK'nın düzenlemesine uygundur.

²⁰³ Mülga 765 s. TCK'nın sistemine göre; "*şartla salıverilmiş olan hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur(sa), ... şartla salıverilme kararı geri alınır.*" (m. 17, f. 1, cümle 1). Buna göre, şartla salıverme kararının geri alınabilmesi için, deneme süresi içinde işlenen suçun *kasten* işlenen bir *cürüm* olması gerekmektedir. Ayrıca, deneme süresi içinde işlenmiş bulunan bu suçtan dolayı, *hürriyeti bağlayıcı cezaya* mahkûm olmak gerekirdi. Buna karşılık, deneme süresi içinde işlenen yeni suç şayet kasten işlenen bir cürüm olmakla birlikte, bu suçtan dolayı mahkûm olunan ceza hürriyeti bağlayıcı ceza değilse, meselâ para cezası ise, şartla salıverme kararı geri alınmamaktaydı. Keza, kişi kasten işlediği cürümden dolayı önce hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmuş ve fakat bu cezası meselâ para cezasına çevrilmiş olabilir. "*Uygulamada asıl*

Ancak, söz konusu fıkra düzenlemesi ile maddenin onbeşinci fıkrası arasında bir çelişki bulunmaktadır²⁰⁴.

Maddenin onbeşinci fıkrasına göre; hükümlü denetim süresi içinde “işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı **hapis cezasına mahkûm edilirse**,” koşullu salıverilme kararının geri alınmasına karar verilir (İnfaz K, m. 107, f. 15).

Bu düzenleme karşısında koşullu salıverilme kararının geri alınması için, hükümlünün denetim süresinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, kişi denetim süresi içinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemekle birlikte, bu suç nedeniyle hakkında hapis cezası yerine seçimlik ceza olarak adli para cezasına hükmedilmiş olabilir. Keza, kişi kasten işlediği suçtan dolayı mahkûm edildiği kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırım olarak adli para cezasına veya güvenlik tedbirine çevrilmiş olabilir. İnfaz Kanununun 107. maddesinin onbeşinci fıkrası düzenlemesi karşısında, bu durumda, 765 s. TCK’nın sisteminde olduğu gibi (m. 17, f. 1, cümle 1), koşullu salıverilme kararı geri alınamayacaktır.

Söz konusu maddenin oniki ve onbeşinci fıkraları arasındaki bu çelişki karşısında; hükümlünün lehine olan, yani onbeşinci fıkraya uygun çözüm biçimini benimseyerek uygulama geliştirmek gerekir. Ancak, bir kanuni düzenlemeyle bu iki fıkra arasındaki çelişkinin giderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca işaret etmemiz gerekir ki; koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için, hapis cezasını gerektiren kasıtlı suçun denetim süresi içinde işlenmesi yeterlidir. Fakat, mahkûmiyet kararının da denetim süresi içinde verilmiş olması gerekmemektedir^{205,206}.

mahkûmiyet, (647 s. Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince) çevrilen para cezası” olduğu için, bu durumda şartla salıverme kararı geri alınmamaktaydı.

²⁰⁴ Yeni İnfaz Kanununa ilişkin Hükümet Tasarısındaki koşullu salıverilmeye ilişkin madde (m. 107) tarafımızdan kaleme alınmıştı. Kanunlaşan madde metnindeki onbeşinci fıkra Hükümet Tasarısında bulunmamaktaydı. (Bu hususta bkz. TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 710).

Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısında yer alan kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükümün açıklanmasının geri bırakılması müesseseleriyle ilgili olarak TBMM Adalet Alt Komisyonunda yaşanan krizin Alt Komisyon üyelerinden Niğde Milletvekili sayın Orhan ERASLAN ile aramda oluşturduğu güvensizlik nedeniyle, yeni İnfaz Kanunu Tasarısının TBMM Adalet Komisyonundaki aynı tarihlere tekabül eden müzakerelerine katılmamak yönünde bir karar vermiştim.

Katılmadığım Komisyon çalışmalarında İnfaz Kanunu Tasarısının 107’nci maddesine eklenen onbeşinci fıkra metni ile Tasarı metninde mevcut olan onikinci fıkra metni arasında bir çelişki ortaya çıkmıştır.

²⁰⁵ «İkinci cürmün birinci cürme ait ceza müddeti içinde (hükümde yazılı müddet) dolmadan işlenmiş olması yeter olup, ayrıca cezanın kesinleşmesinin bu süre içinde gerçekleşmiş olması şart değildir. ... Bu bakımdan TCK’nın 17. maddesinin 1. fıkrasında yazılı “mahkûm olur” sözü “cürm işler” manasında anlamak zorunlu bulunmaktadır. ... 17. maddenin aradığı unsur; ilk cürmden dolayı hükümlünün meşruten tahliye tarihi ile bihakkin tahliye edilmesi gereken tarih arasında kasdî bir cürmden dolayı şahsî hürriyeti bağlayıcı bir cezayı gerektiren

Hükümlünün denetim süresi içinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi halinde, koşullu salıverilme kararı kendiliğinden düşmeyip²⁰⁷, bir kararla geri alınması gerekir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına, **infaz hakimliği** tarafından dosya üzerinden karar verilir. Bu karara karşı itiraz yolu açıktır (İnfaz K, m. 107, f. 15)²⁰⁸.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için, işlenen ikinci suçtan dolayı verilmiş bulunan mahkûmiyet kararının kesinleşmesi beklenmelidir²⁰⁹.

Koşullu salıverilen mahkûmun denetimli serbestlik tedbirinin gereği olarak kendisine yüklenen yükümlülükleri denetim süresi içinde yerine getirmemesi durumunda dahi, koşullu salıverilme kararı geri alınır:

“Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde ... kendisine yüklenen yükümlülüklerle, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.” (İnfaz K, m. 107, f. 12).

Ancak, bunun için, önce infaz hakiminin hükümlüye uyarıda bulunması ve bu uyarıya rağmen hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinin gereği olan yükümlülüklerine uymamakta ısrar etmesi gerekir.

bir cürmün işlenmiş olması keyfiyettir.»: Yarg. İBK., 8.6.1970, 1969/9, 1970/4 (YKD, Şubat 1975, sh. 18 vd.; RKD, 1971, sayı 1-12, Bölüm I/1, sh. 13 vd.; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Ceza-III, 2. bası, Ankara, 1984, sh. 850 vd.). Ayrıca bkz. 5. CD., 26.2.1969, 480/686 (RKD, 1969, sayı 1-12, bölüm III/2, sh. 110 vd.). Ayrıca bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 861; CENTEL, Hukuk Araştırmaları 7(1992-1993), sh. 63.

²⁰⁶ Dönmezer/Erman, bu durumda şartla salıverme kararının geri alınabilmesi için, deneme süresi içinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet kararının da deneme süresi içinde verilmesi gerektiği fikrindedirler (DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1745).

²⁰⁷ Bazı kitaplarda şartla salıverme kararının “düşmesi” ifadesi kullanılmaktadır (Bkz. ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 227; ÖZTÜRK[3], sh. 307). Kanımızca, yanlış anlaşılmaya neden olabilecek olan bu ifadenin kullanılmaması gerekir.

²⁰⁸ Koşullu salıverilme ile bağlantılı olarak **farklı infaz hakimlikleri** yetkili kılınmıştır. Kanuni düzenlemeye göre;

a) Koşullu salıverilmeye karar verme hususunda, “**infaz işlemlerinin yapıldığı yer infaz hakimliği**” (İnfaz K, m. 107, f. 11),

b) Koşullu salıverilme kararının geri alınması konusunda ise, “**hüküm veren ilk derece mahkemesinin bulunduğu yer infaz hakimliği, cezaların toplandığı hâller ile hükmün bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmiş olması hâlinde ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen infaz hakimliği**” (İnfaz K, m. 107, f. 15),

yetkili kılınmıştır.

Koşullu salıverildikten sonra başka bir yere giden hükümlü ile ilgili olarak denetim süresi zarfındaki iş ve işlemler bağlamında bulunduğu yer infaz hakimliğinin de yetkilendirilmesi ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, bir yetki kargaşasının ve gereksiz bürokratik işlem sürecinin ortaya çıkacağı göz ardı edilmemelidir.

²⁰⁹ CGK., 6.10.1986, 6-208/422 (YKD, Aralık 1986, sh. 1816 vd.); 4. CD., 15.11.1985, 7973/8201 (YKD, Ağustos 1986, sh. 1219); 4. CD., 24.4.1985, 3284/3615 (YKD, Temmuz 1985, sh. 1067)6.

Bu durumda infaz hakimi tarafından koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dosya üzerinden karar verilir. Bu karara karşı itiraz yolu açıktır (İnfaz K, m. 107, f. 15).

“Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde hükümlünün;

a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren başlamak ve hak ederek tahliye tarihini geçmemek koşuluyla sonraki işlediği her bir suç için verilen hapis cezasının iki katı sürenin,

b) Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla ihlalin niteliğine göre takdir edilecek bir sürenin,

Ceza infaz kurumunda aynen çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.” (İnfaz K, m. 107, f. 13).

Buna göre, denetim süresi içinde işlediği kasıtlı suç nedeniyle hakkında hükmedilen hapis cezasının kesinleşmesi üzerine koşullu salıverilme kararı geri alınan hükümlünün, koşullu salıverilme tarihinde kalan ceza miktarını değil, koşullu salıverilme kararının geri alınmasını gerektiren suçun işlendiği tarihten itibaren cezanın kalan kısmını aynen çekecektir²¹⁰.

Buna karşılık, hükümlünün, denetimli serbestlik tedbirinin gereği olarak kendisine yüklenen yükümlülüklerle *“aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek* (kaydıyla, koşullu salıverilme kararını geri alan infaz hakimince) *ihlalin niteliğine göre takdir edilecek bir sürenin, ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.”*

Cezasını tekrar infaz kurumunda çekmeye başlayan mahkûm, bu mahkûmiyet kararıyla ilgili olarak bir daha koşullu salıverilmeden yararlanamaz. Ancak, bu hüküm, kişinin işlediği sair suçlardan dolayı mahkûm olduğu cezaların infazı açısından koşullu salıverilmeden yararlanmasına engel teşkil etmemektedir.

X. Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı

İnfaz Kanununa 5.4.2012 tarihli ve 6291 sayılı Kanunla eklenen 105/A maddesi hükümlerine göre,

- mahkum olduğu hapis cezasının infaz kurumunda çekilmesi sürecinde “açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve **koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlü**”nın

- talebi halinde,

²¹⁰ 9. CD., 25.4.1994, 2297/2257 (YKD, Eylül 1998, sh. 1402). Bu düzenleme, 7.12.1988 tarih ve 3506 sayılı Kanunla mülga 765 s. TCK’nın 17. maddesinde yapılan değişiklikle uyum içindedir.

- cezasının “koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle (yani infaz kurumu dışında, toplumsal ortamda) infazına” karar verilebilir (m. 105/A, f. 1)^{211,212}.

Bu karar, “ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu yer **infaz hâkimi** tarafından” verilir.

Bu suretle, hapis cezasının infazı sürecinde, cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlü, hakkında henüz **koşullu salıverilme hükümleri uygulanmadan önce**, denetimli serbestlik tedbiri altında **infaz kurumundan dışarı çıkarılabilmektedir**. Dikkat edilmelidir ki, bu imkandan yararlanma bakımından **işlenen suçlar itibarıyla bir istisna öngörülmemiştir**.

Buna göre, örneğin kasten yaralama, yağma, hırsızlık dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı gibi suçlardan birinden mahkum olan kişinin koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için mahkum olduğu hapis cezasının **yarısını** çekmiş olması gerekmektedir (İnfaz K. m. 107, f. 2). Mesela **silahla işlenmiş ve mağdurun ölümüyle sonuçlanmış** olan neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış **kasten yaralama** suçundan dolayı **16 yıl** hapis cezasına mahkum olan kişi, “açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde” bulunması ve iyi halli olması koşuluyla, koşullu salıverilme tarihinden **bir yıl önce**, yani ceza infaz kurumunda **7 yıl** kaldıktan sonra, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkarılabilecek ve cezasının infazına kurum dışında, toplumsal ortamda devam edilebilecektir.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek, kasten öldürme, işkence ve eziyet gibi suçlardan birinden mahkum olan kişinin koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için mahkum olduğu hapis cezasının **üçte ikisini** çekmiş olması gerekmektedir (İnfaz K. m. 107, f. 2, 4). Mesela kasten öldürme suçunu işlediği için **24 yıl** hapis cezasına mahkum olan kişi, “açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde” bulunması ve iyi halli olması koşuluyla, koşullu salıverilme tarihinden **bir yıl önce**, yani ceza infaz kurumunda **15 yıl** kaldıktan sonra, hakkında denetimli ser-

²¹¹ “Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.” (İnfaz K. m. 105/A, f. 2).

²¹² Keza,

- sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve **koşullu salıverilmesine iki yıl** veya daha az süre **kalan** kadın hükümlüler,
- maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve **koşullu salıverilmesine üç yıl** veya daha az süre **kalan** hükümlüler,
diğer şartları taşımaları hâlinde bu imkandan yararlanabilirler (İnfaz K. m. 105/A, f. 3).

bestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkarılabilecek ve cezasının infazına kurum dışında, toplumsal ortamda devam edilebilecektir.

Terör örgütü kurmak veya yönetmek, cinsel istismar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi suçlardan birinden mahkum olan kişinin koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için mahkum olduğu hapis cezasının **dörtte üçü**nü çekmiş olması gerekmektedir (İnfaz K, m. 108, f. 9; 3713 s. TMK, m. 17, f. 1). Mesela uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği için **12 yıl** hapis cezasına mahkum olan kişi, “*açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde*” bulunması ve iyi halli olması koşuluyla, koşullu salıverilme tarihinden **bir yıl önce**, yani ceza infaz kurumunda **7 yıl** kaldıktan sonra, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkarılabilecek ve cezasının infazına kurum dışında, toplumsal ortamda devam edilebilecektir^{213,214}.

²¹³ Ancak İnfaz Kanunu’nun 7242 s. Kanunla değişik Geçici madde 6 hükümlerine göre, **30.3.2020 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan dolayı** hükmolunan hapis cezasının infazı sürecinde hükümlü, **koşullu salıverilmesine üç yıl kala**, iyi hâlli olması koşuluyla ve talebi hâlinde, **infaz kurumundan dışarı çıkarılabilmektedir**. Fakat bu geçici madde hükmünün uygulanabilmesi bakımından 30.3.2020 tarihinden önce işlenmiş olmasına rağmen belirli suçlar **hariç** tutulmuştur.

Bu istisna kapsamında;

- kasten öldürme suçları (TCK, m. 81, 82, 83),
- üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçları,
- “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları”,
- “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu” (TCK, m. 87, f. 2, bent d),
- işkence suçu (TCK, m. 94 ve 95),
- eziyet suçu (TCK, m. 96),
- cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK, m. 102, 103, 104, 105),
- özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK, m. 132 ilâ 138),
- uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK, m. 188),
- TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar,
- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar,

sayılmıştır. Bu istisnai suçların sayılması bağlamında **özensiz** bir **kanuni düzenleme** örneği ile karşı karşıya bulunmaktayız: Şöyle ki, kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış bütün halleri istisna kapsamında iken, 7242 s. Kanunla bu istisnalara ayrıca, kasten yaralama suçunun mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine sebebiyet vermesi hali eklenmiştir.

Bu hükümlere göre, belirli istisnai suçlar hariç olmak üzere, 30.3.2020 tarihine kadar işlenmiş olan bir suçtan dolayı mahkum olunan hapis cezasının infazı sürecinde daha erken bir zamanda denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkılabilmesinin yolu açılmıştır. Örneğin 30.3.2020 tarihinden önce **silahla işlenmiş ve mağdurun ölümüyle sonuçlanmış** olan neticesi sebebiyle ağırlaşmış **kasten yaralama** suçundan dolayı **16 yıl** hapis cezasına mahkum olan kişi, “*açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde*” bulunması ve iyi halli olması koşuluyla, koşullu salıverilme tarihinden **üç yıl önce** (İnfaz K, geçici m. 6, f. 1), yani ceza infaz kurumunda **5 yıl** kaldıktan sonra, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkarılabile-

cek ve cezasının infazına kurum dışında, toplumsal ortamda devam edilebilecektir. Bu hükümlülerin, ayrıca devletin gözetim ve denetimi altında tutulmaksızın, yani denetimsiz olarak “izinli” sayıldıklarını da gözden uzak tutmamak gerekir (İnfaz K, geçici m. 9, f. 5).

Keza, söz konusu geçici madde 6 hükümlerine göre; 30.3.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından,

- sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki yıl”lık süre, “dört yıl” olarak uygulanır (f. 2, bent a);

- maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilir (f. 2, bent b).

Ancak bu hükümler bakımından da belirli suçlar istisna kılınmıştır:

- kasten öldürme suçları (TCK, m. 81 ilâ 83),
- cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK, m. 102 ilâ 105),
- özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK, m. 132 ilâ 138),
- TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar,
- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

²¹⁴ İnfaz Kanununda değişiklik yapan 7242 sayılı Kanuna ilişkin Teklifte, koşullu salıverilme öncesi denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz kurumu dışında çektirilmesi ile ilgili olarak **oransal** bir **sistem** getirilmek istenmişti. Bu sistem, TBMM Adalet Komisyonunda aynen kabul edilmişti.

Buna göre, mahkûm olduğu hapis cezasının koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için çekmesi gereken kısmının **beşte dördünü** ceza infaz kurumunda çeken hükümlü, denetimli serbestlik tedbiri uygulamasıyla infaz kurumu dışına çıkarılarak, cezasını toplumsal ortamda çekmeye devam edebilecekti.

Mesela **silahla işlenmiş ve mağdurun ölümüyle sonuçlanmış** olan neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış **kasten yaralama** veya **yağma** suçundan dolayı **15 yıl** hapis cezasına mahkûm olan kişi, “**açık ceza infaz kurumunda**” bulunması ve iyi halli olması koşuluyla, ceza infaz kurumunda **6 yıl** kaldıktan sonra, yani mahkûm olduğu cezanın **beşte ikisini** infaz kurumunda çektikten sonra, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkarılabilecek ve cezasının infazına kurum dışında, toplumsal ortamda devam edilebilecekti.

Ancak, 7242 sayılı Kanuna ilişkin Teklifin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında verilen bir önergenin kabulüyle tekrar sabit miktar sistemine geri dönmüştür. Buna göre, bu hükümlü, ceza infaz kurumunda **6 yıl 6 ay** kaldıktan sonra, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkarılabilecek ve cezasının infazına kurum dışında, toplumsal ortamda devam edilebilecektir (İnfaz K, m. 105/A, f. 1).

Bu suçu **30 Mart 2020 tarihinden önce** işlemiş olan hükümlü ise, “**açık ceza infaz kurumunda**” bulunması ve iyi halli olması koşuluyla, ceza infaz kurumunda **4 yıl altı ay** kaldıktan sonra, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkarılabilecek ve cezasının infazına kurum dışında, toplumsal ortamda devam edilebilecektir (7242 sayılı Kanunla değiştirilen İnfaz Kanunu, Geçici madde 6, f. 1).

Keza, mesela 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal sürecinde kapatılan bir vakfın, derneğin veya sendikanın yöneticisi olan kişi, bu sebeple “**silahlı terör örgütü yöneticisi**” olarak mahkûm olduğu **16 yıl** hapis cezasının infazı sürecinde, “**açık ceza infaz kurumunda**” bulunması ve iyi halli olması koşuluyla, ceza infaz kurumunda takriben **9 yıl 10 ay** kaldıktan sonra, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkarılabilecek ve cezasının infazına kurum dışında, toplumsal ortamda devam edilebilecekti.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

- a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
- b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
- c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
- d) Belirlenen programlara katılması,

yükümlülüklerinden bir veya birkaçına tabi tutulmasına, **denetimli serbestlik müdürlüğünce** karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir (m. 105/A, f. 5)²¹⁵.

Hükümlünün;

- Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne beş gün içinde müracaat etmemesi,
- Hakkında belirlenen yükümlülüklerle, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,

veya

- Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir. Bu infaz hakimi, denetimli serbestlik müdürlüğünün bulunduğu yer infaz hakimidir (İnfaz K, m. 105/A, f. 6).

Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, koşullu salıverilme kararı çerçevesinde değerlendirilmek üzere infaz hakimliğine gönderilir (İnfaz K, m. 105/A, f. 9)²¹⁶.

Oysa kanunlaşan metne göre, bu hükümlü, ceza infaz kurumunda **11 yıl** kaldıktan sonra, hakkındaki denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumu dışına çıkarılabilecek ve cezasının infazına kurum dışında, toplumsal ortamda devam edilebilecektir (İnfaz K, m. 105/A, f. 1).

Sözün özü, **7242 sayılı Kanunla infaz sistemimiz, ancak “mahir” infaz hakimlerimiz tarafından özel bir bilgiyle anlaşılabilir, bırakın herhangi bir vatandaşın, bir hukukçunun bile anlamakta güçlük çektiği ve içinden çıkamayacağı bir dille kurgulanmıştır.**

²¹⁵ Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin (RG: 10 Kasım 2021/31655) 77 vd. maddelerinde, hapis cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır.

²¹⁶ 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle koşullu salıverilmeye ve koşullu salıverilme kararının geri alınmasına karar vermeye **infaz hakimi** yetkili kılınmasına rağmen, bu fıkradaki “mahkemeye” ibaresinin değiştirilmesi gereği gözden kaçırılmıştır.

Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve **cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması** hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hâkimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilir. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir (İnfaz K, m. 105/A, f. 7).

Bu düzenlemeleri itibarıyla söz konusu 105/A maddesi ile, **koşullu salıverilme uygulaması öne çekilmiş olmaktadır**. Ancak, hapis cezasının denetimli serbestli tedbiri uygulamasıyla kurum dışında çekilebilmesi için, **hükümlünün talepte bulunması gerekir**. Buna karşılık koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için, hükümlünün talepte bulunmasına gerek yoktur; koşullu salıverilmeye re'sen karar verilir.

Buna karşılık, koşullu salıverilmede olduğu gibi, hapis cezasının denetimli serbestli tedbiri uygulamasıyla kurum dışında çekilebilmesi için, **hükümlünün iyi halli olması gerekir**. Koşullu salıverilme bağlamında iyi halliliğe ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar, hapis cezasının denetimli serbestli tedbiri uygulamasıyla kurum dışında çekilebilmesi bağlamında da göz önünde bulundurulmalıdır.

XI. Özel İnfaz Şekilleri

A. Hafta Sonu veya Geceleri İnfaz

Kasten işlenen suçlardan dolayı mahkum olunan toplam **bir yıl altı ay**, taksirle ölüme sebebiyet verme hariç olmak üzere, **taksirle** işlenen bir suçtan dolayı mahkum olunan toplam **üç yıl hapis cezası**, hafta sonları veya geceleri infaz edilebilir (İnfaz K, m. 110, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 40, f. 1²¹⁷). Bu bir yıl altı aylık veya üç yıllık hapis cezaları, bir suçtan dolayı hükmedilebileceği gibi, birden fazla suçtan dolayı da hükmedilebilir. Ancak birden fazla suçtan dolayı hükmedilen hapis cezalarının toplamı, kasten işlenen suçlarda bir yıl altı ayı, taksirle işlenen suçlarda ise üç yılı geçmemesi gerekir.

Hafta sonu infazda hükümlü cezasını, “*her hafta cuma günleri saat 19.00’da (ceza infaz kurumuna) girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle*” çeker.

Geceleri infazda ise, hükümlü cezasını “*hafta sonları hariç, gün saat 19.00’da (ceza infaz kurumuna) girmek ve ertesi gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle*” çeker.

²¹⁷ Dikkat edilmelidir ki, İnfaz Kanununda 7242 sayılı Kanunla yapılan özel infaz usullerine ilişkin değişiklikler, İnfaz Yönetmeliği’ne 12.11.2021 tarihli, RG: 31657 sayılı Yönetmeliğin 16. maddesiyle eklenmiştir.

Bu hükümlüler, kurumlarda diğerlerinden ayrı yerlerde barındırılır. Hükümlü, bu fıkra da belirtilen yükümlülükler e uymaması hâlinde durum, kurum tarafından Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir (İnfaz Yönetmeliđi, m. 40, f. 1).

Hafta sonu veya geceleri infaza, ancak **hükümlünün talebi üzerine infaz hakimi karar** verebilir. Bu itibarla, 7242 s. Kanunla yapılan deđişiklikten sonraki düzenlemeye göre, artık hapis cezasının hafta sonları veya geceleri infazına hüküm veren mahkemece mahkumiyet hükmüyle birlikte deđil, hüküm verilip kesinleştikten sonra ve hatta, infaz aşamasında infaz hakimi tarafından karar verilecektir.

B. Konutta İnfaz

Mahkûmiyetin sebebini oluşturan suçun işlenmesiyle doğmuş olan zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere;

- a) Kadın, çocuk veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam **bir yıl**,
- b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam **iki yıl**,
- c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam **dört yıl**,

veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine **infaz hakimi** tarafından karar verilebilir (İnfaz K, m. 110, f. 2; İnfaz Yönetmeliđi, m. 40, f. 2²¹⁸).

Bu bir, iki ve dört yıllık hapis cezaları, **kasıtlı veya taksirli** bir suçtan dolayı hükmedilebileceđi gibi, birden fazla suçtan dolayı da hükmedilebilir. Ancak birden fazla suçtan dolayı hükmedilen hapis cezalarının toplamı, bu süreleri aşmaması gerekir.

Konutta infaza, hüküm veren mahkemece mahkumiyet hükmüyle birlikte deđil, hüküm verilip kesinleştikten sonra ve hatta, infaz aşamasında infaz hakimi tarafından karar verilecektir.

Cezanın infaz edileceđi yerin, hükümlünün resmi ikametgahının olması gerekmektedir. İnfaz hakiminin kararında hükümlünün cezasını konut olarak hangi adreste çekeceđi belirtilir.

Konutta infaza ilişkin ilâmlar, Cumhuriyet başsavcılıklarınca infazı amacıyla denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir ve cezalar Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliđi hükümlerine göre infaz edilir (İnfaz Yönetmeliđi, m. 40, f. 2, bent b).

²¹⁸ Dikkat edilmelidir ki, İnfaz Kanununda 7242 sayılı Kanunla yapılan özel infaz usullerine ilişkin deđişiklikler; İnfaz Yönetmeliđi'ne, 12.11.2021 tarihli, RG: 31657 sayılı Yönetmeliđin 16. maddesiyle eklenmiştir.

7242 s. Kanun değişikliği ile, konutta infazın alanı genişletilmiştir. Buna göre:

“Toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden 16’ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen usule göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilir.” (İnfaz K, m. 110, f. 3; İnfaz Yönetmeliği, m. 40, f. 3).

Keza,

“Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için kadının doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekir. Konutta infaza en geç bu süre sonunda başlanır. Konutta infaza karar verdikten sonra çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa infaz hâkimi konutta infaz uygulamasına ilişkin kararını kaldırır.” (İnfaz K, m. 110, f. 4; İnfaz Yönetmeliği, m. 40, f. 4).

C. Ortak Hükümler

“Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler hakkında tâbi oldukları infaz rejimine göre koşullu salıverilme hükümleri uygulanır. Ancak, 105/A maddesi hükümleri uygulanmaz.” (İnfaz K, m. 110, f. 5; İnfaz Yönetmeliği, m. 40, f. 5).

Yukarıda da belirtildiği gibi, özel infaz usullerine karar vermeye hükmü veren mahkeme değil, infaz hakimi yetkili kılınmıştır. Bu nedenle, cezanın özel infaz usullerinden birine göre infazına hüküm kesinleştikten sonra ve hatta, infaz aşamasında karar verilebilecektir (İnfaz K, m. 110, f. 6; İnfaz Yönetmeliği, m. 40, f. 6).

“İnfaz hakimi talep üzerine, cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi sırasında bu usulün uygulanmasına son verebilir. Özel infaz usulünün gereklerine geçerli bir mazeret olmaksızın uyulmaması hâlinde ise bu usulün uygulanmasına son verilir ve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilir. Özel infaz usulüne göre geçirilen süre, infaz aşamasında mahsup edilir. Bu fıkranın uygulandığı hallerde 105/A maddesi hükümleri uygulanmaz.” (İnfaz K, m. 110, f. 7; İnfaz Yönetmeliği, m. 40, f. 7).

“Üçüncü ve dördüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri;

- a) Terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar,*
- b) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar,*

c) *Adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,*

d) *Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler,*

hakkında uygulanmaz.” (İnfaz K, m. 110, f. 9; İnfaz Yönetmeliği, m. 40, f. 9).

İnfaz hakimliği tarafından özel infaz usulüne ilişkin olarak verilen kararlara itiraz edilebilir. (İnfaz K, m. 110, f. 8; İnfaz Yönetmeliği, m. 40, f. 10).

XII. Hapis Cezası ve Disiplin Hapsi

Bir kamusal faaliyetin yürütülmesine ilişkin kurallara aykırı davranışlar, bu faaliyetin yürütülmesini aksatan bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, kamusal faaliyetin yürütülmesine ilişkin kurallara aykırı davranışta bulunan kişiler hakkında, **kurallara uygun davranmalarını sağlamak amacıyla** disiplin yaptırımı uygulanmaktadır. **Disiplin hapsi**, bu yaptırımlardan birini oluşturmaktadır, yani bir disiplin cezasıdır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda disiplin hapsi tanımlanmıştır (m. 2, f. 1, bent 1):

“Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, ifade eder.”²¹⁹

Bu tanımlamada, disiplin hapsinin sadece sonuçlarına işaret edilmiştir; yani, disiplin hapsinin bir hapis cezası olmadığı ve dolayısıyla, kanunlarda adli cezalarla bağlantılı olarak düzenlenen müesseselerin disiplin hapsiyle ilgili olarak uygulanamayacağı vurgulanmıştır. Bu bakımdan, hapis cezasından farklı olarak, disiplin hapsinin, kişi hakkında, belli bir süreye kadar hürriyetinden yoksun bırakılmasının dışında, **hak yoksunluğu gibi başka herhangi bir hukuki sonucu bulunmamaktadır**²²⁰.

Hapis cezasıyla disiplin hapsi arasında bir başka fark daha bulunmaktadır. Kanunda, hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili olarak, kanuni tanımlardaki hapis cezası süreleri göz önünde bulundurularak, *dava zamanaşımı süreleri* belirlenmiştir. Buna karşılık, örneğin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda 31.5.2005

²¹⁹ Söz konusu maddenin başında “Bu Kanunun uygulanmasında” ibaresine yer verilmiş ise de; bu ibareden, maddede yapılan tanımların 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun uygulama alanıyla sınırlı tutulduğu şeklinde bir sonuç çıkarılmamalıdır. Zira, Ceza Muhakemesi Kanununun, genel bir kanundur.

²²⁰ Disiplin hapsinin hukuki niteliği ile ilgili değerlendirmeler için ayrıca bkz. CGK, 25.4.2006, E. 2006/16.HD-123, K. 2006/127.

tarihli ve 5358 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde²²¹, *disiplin hapsine karar verilebilmesi için*, disiplin hapsi süresi göz önünde bulundurularak bir *zamanaşımı süresi* öngörülmemiştir²²². Bunun ifade ettiği anlam şudur: Kişinin belli bir yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, bu yükümlülüğe uygun davranmasını sağlamak amacıyla hakkında disiplin hapsine karar verilmektedir. Bu bakımdan kişinin örneğin belli alacak borç ilişkisinden kaynaklanan ifa yükümlülüğü mevcudiyetini devam ettirdiği sürece bu yükümlülükle ilgili olarak hakkında disiplin hapsine karar verilebilecektir.

Disiplin hapsinin hapis cezasıyla müşterek yönleri de bulunmaktadır. Şöyle ki;

1. Kanunda açık bir şekilde belirlenen bir yükümlülüğe aykırı davranışı dolayısıyla kişi hakkında disiplin hapsi uygulanabilir. Başka bir deyişle, **hangi fiiller karışığında disiplin hapsinin uygulanabileceği ancak kanunla belirlenebilir**.

2. Disiplin hapsinin **süresi kanunla belirlenebilir**. Bu süre, maktu²²³ veya üst sınırı gösterilmek suretiyle²²⁴ belirlenmiş olabilir.

²²¹ RG: 1 Haziran 2005/25832.

²²² Buna karşılık, İcra ve İflas Kanununun 354. maddesinde 5358 sayılı Kanunla yapılan değişiklik, disiplin hapsi ile ilgili olarak sadece *yerine getirme zamanaşımı süresi* öngörülmüştür.

²²³ Örneğin, 9.6.1932 t. ve 2004 s. İcra ve İflas Kanununun “Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” başlıklı 337’nci maddesine göre;

“Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya yazılı beyanda bulunmayan borçlu, alacaklının şikâyeti üzerine, **on gün disiplin hapsi** ile cezalandırılır. Alacaklının alacağını karşılayacak miktarda malın haczedilmesi veya borcun ödenmesi hâlinde, bu ceza düşer.” (fıkra 1).

“162, 209 ve 216’ncı maddeler hükümlerine muhalefet edenler hakkında da iflas idaresinin vereceği müzekkere üzerine, aynı ceza verilir. Bu maddelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde, verilen ceza düşer.” (fıkra 2).

²²⁴ Bu konuda Ceza Muhakemesi Kanunundan şu örnekler gösterilebilir:

“Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, **yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için** dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde **üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi** verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest bırakılır.” (5271 s. Kanun, m. 60, f. 1).

Keza, bir olayda “*ispat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri*”ni elinde bulunduran kişi, bunları soruşturma ile görevli kişilere göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür (5271 s. Kanun, m. 124, f. 1). Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden kaçınılması halinde de, “*60 ıncı maddede yer alan disiplin hapsine ilişkin hükümler uygulanır.*” (5271 s. Kanun, m. 124, f. 2).

Duruşmanın düzenini korumak amacıyla, mahkeme başkanı veya hâkim, kişinin salondan çıkarılmasını emredebilir (5271 s. Kanun, m. 203, f. 2).

“*Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hâkim veya mahkeme tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhâl **dört güne kadar disiplin hapsine** konulabilir. Ancak çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmaz.*” (5271 s. Kanun, m. 203, f. 3).

3. Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmasının sonuçlaması itibarıyla, disiplin hapsine ancak **hakim karar verebilir**.²²⁵

Kişinin yükümlülüğe aykırı davranmamak konusunda mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak, kişi, bazı durumlarda bir yükümlülüğe uygun davranmaya belli ölçüde icbar edilebilmektedir. Başka bir deyişle, kişi, bazı durumlarda yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmesini sağlamak için, belli ölçüde icbar edilebilmekte ve bu amaçla bir süreye kadar hürriyetinden yoksun bırakılabilmektedir. Bu hürriyetten yoksun bırakma olgusu, bir **disiplin hapsi** niteliği taşımaktadır. Ancak, yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde, bu yaptırımın uygulanmasına derhal son verilmektedir. Bu bakımdan söz konusu disiplin hapsine ilişkin olarak kanunda sadece azami bir süre belirlenmektedir. Kişi kendisine terettüp eden yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye zorlanmak amacıyla ancak belli bir süreye kadar hürriyetinden yoksun bırakılabilecektir. Bu sürenin dolması halinde; kişi, yükümlülüğünün gereğini yerine getirmemiş olsa bile, hürriyetinden yoksun bırakılmasına ilişkin yaptırım uygulanmasına son verilecek, serbest bırakılacaktır. Bu nedenle, söz konusu disiplin hapsine, Kanunda²²⁶ **tazyik hapsi** veya **zorlama hapsi**²²⁷ denmiştir.²²⁸

Bu konuda İcra ve İflas Kanununda da hükümler bulunmaktadır (Örnek olarak bkz. 2004 s. Kanun, m. 339, f. 1).

²²⁵ Bu konuda bkz. 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunu, m. 60, f. 2; m. 203, f. 3; 2004 s. İcra ve İflas Kanunu, m. 346, f. 1.

²²⁶ Bkz. 2004 s. İcra ve İflas Kanunu, m. 338 (f. 2), 340, 341, 343, 344 (f. 1).

²²⁷ 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı **Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun** (RG: 20 Mart 20012/28239). "**Tedbir kararlarına aykırılık**" başlıklı 13. maddesine göre, şiddet uygulaması veya uygulama tehlikesi bulunması dolayısıyla hakkında **önleyici tedbir kararı** verilen kişi, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, kendisine yüklenen yükümlülüklerle uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla **zorlama hapsine** tabi tutulacaktır.

Şiddet uygulayan kişinin fiilinin **suç oluşturmaması halinde dahi**, bu zorlama hapsi uygulanacaktır. Fiilin suç oluşturmaması sebebiyle **ayrıca** kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir.

Zorlama hapsine ancak aile **hakimi** tarafından **karar** verilebilecektir.

Zorlama hapsinin azami süresi Kanunla belirlenmiştir. Buna göre, kişi hakkında ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre üç günden on güne kadar **zorlama hapsi** uygulanabilecektir. Zorlama hapsinin ne kadar süre ile uygulanacağı hakim kararında gösterilecektir.

Önleyici tedbir kararının gereklerine aykırılığın tekrarında, zorlama hapsinin süresi uzatılabilecektir. Bu itibarla belirli bir olay bağlamında kişiye yüklenen yükümlülüklerin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla zorlama hapsinin uygulanmasına rağmen, yükümlülüklerle aykırı davranmakta ısrar edilmesi halinde, yeniden zorlama hapsi kararı verilecektir. Ancak bu durumda tekerrür dolayısıyla zorlama hapsinin süresi hakim kararında onbeş günden az ve otuz günden fazla olmayacak şekilde belirlenecektir. Ancak belirtmek gerekir ki, **bir olay bağlamında kişi hakkında uygulanacak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez**.

Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet savcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, hakkında **önleyici tedbir kararı** verilen kişinin fiilinin suç oluşturması halinde de, bu tedbirin gereklerine aykırı hareket ettiği takdirde, hakkında zorlama hapsi uygulanabilecektir. Bu bağlamda iki ihtimal söz konusu olabilir. Birinci ihtimalde, işlediği fiilin suç oluşturması sebebiyle kişi hakkında önleyici tedbir kararı alınmıştır. İkinci ihtimalde ise, hakkında **önleyici tedbir kararı** verilen ve uygulanan kişi, suç oluşturan yeni bir fiil işlemek suretiyle bu tedbirin gereklerine aykırı hareket etmiştir. Her iki ihtimalde de, bu kişi hakkında zorlama hapsi uygulanabilecektir. İşlediği fiilin suç oluşturması sebebiyle kişi hakkında ayrıca soruşturma ve kovuşturma yapılacaktır. Şayet kişi bu soruşturma veya kovuşturma sürecinde örneğin tutuklanmış ise, tutuklu kaldığı süre zarfında hakkında artık önleyici tedbir kararı uygulanamaz ve dolayısıyla zorlama hapsine tabi tutulamaz. Bu bağlamda, 6284 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “Şiddet Uygulayan Kişinin Zorlama Hapsine Tabi Tutulması”, in: Yoncalı Platformu Sempozyum Günleri, Kütahya, Türkiye’de Aile İçi Şiddetle Mücadele Hukuk Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuku Dergisi, yıl 2012, cilt 8, sayı 97-98, sh. 59 vd.

Anayasa Mahkemesi, 6284 s. Kanunun 13. maddesinin söz konusu düzenlemesinin aşağıdaki **gerekçe** ile Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir (28.11.2013 tarihli ve E. 2013/119, K. 2013/141 sayılı Karar; RG: 27 Mart 2014/28954):

“İtiraz konusu kuralda yer alan zorlama hapsi, bir suç karşılığı uygulanan **ceza değildir. Zorlama hapsi**, hukuki niteliği itibarıyla tedbir kararına uyma yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlayan ve bu yükümlülüğün ihlali hâlinde öngörülen bir **disiplin hapsidir**.

Bu nedenle zorlama hapsi, **bir hapis cezası olmayıp**, şiddet uygulayan tedbirlere uymaya zorlayarak neticesi ağır suçların işlenmesinden önce suçun önlenmesini amaçlayan bir yaptırım olduğundan ceza kavramı dışında değerlendirilmesi gerekir. İtiraz konusu kuralda, zorlama hapsi yaptırımına bağlanan eylem, tedbir kararına uymama eylemi olup tedbir kararına aykırı davranan kişi kamu otoritesi tarafından verilen bir karara aykırı davrandığı için zorlama hapsi yaptırımı ile karşılaşmaktadır. Kişinin tedbir kararma aykırı davranışı, aynı zamanda bir suç oluşturuyor ise bu durum, hukuk düzeninin koruduğu farklı hukuksal menfaatlerin ihlali sonucunu doğuracağından mükerrer cezalandırmadan söz edilemez.

Tedbir kararlarının gereklerine uymaya zorlayarak şiddet mağdurunu etkin biçimde korumaya ve Kanun’un amacını gerçekleştirmeye yönelik itiraz konusu kural, kanun koyucunun takdir alanı içerisinde ve itiraz konusu kuralın hukuk devleti ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır.”

228 Kişiler, “görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili (doğru) bilgi” vermekle yükümlüdür (30.3.2005 t. ve 5326 s. Kabahatler Kanunu, m. 40, f. 1 ve madde gerekçesi).

“Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılincaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.” (5326 s. Kanun, m. 40, f. 2).

“Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.” (5326 s. Kanun, m. 40, f. 3).

“Kimliği konusunda bilgi vermediği veya yanlış bilgi verdiği için asıl kimliği belirlenemeyen kişi, kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla tutulabilecek, gözaltına alınabilecek ve gerektiğinde tutuklanabilecektir. Kamu görevlisi tarafından tutulan kişi, Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltına alınabilecektir. Gözaltı süresi dolmasına rağmen kimliği belirlenemeyen kişinin, bu amaçla sulh ceza hâkimi tarafından tutuklanmasına karar verilecektir. Burada ceza muhakemesi amacıyla başvurulmuş bir koruma tedbirleri söz konusu olmadığından, bu tedbirler için aranan bütün şartlar aranmayacaktır. Ancak bu tedbirlere başvurmayla karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Örneğin, kişi özgür-

Disiplin hapsi olarak tazyik hapsine de ancak **hakim** tarafından **karar** verilebilmektedir.

Tazyik hapsi uygulamasının da, bir disiplin hapsi niteliğini taşıması itibarıyla, kişi hakkında, azami sınırı belli olan bir süreye kadar hürriyetinden yoksun bırakılmasının dışında, **hak yoksunluğu gibi** başka herhangi **bir hukuki sonucu bulunmamaktadır**.

XIII. Adli Para Cezası

I. Ceza hukukunda ceza olarak ikinci yaptırım, adli para cezasıdır. Adli para cezası, Kanun koyucunun takdirine bağlı olarak ancak belirli ağırlık derecesine ulaşmamış olan suçlar dolayısıyla kabul edilmiş olan bir yaptırımdır. Bu ceza, daha ziyade tesadüfi suçlular bakımından uygulanmaktadır.

Yaptırım teorisinde adli para cezası, genellikle hapis cezasına alternatif bir yaptırım olarak değerlendirilmiştir. Adli para cezası, belirli ağırlık derecesine ulaşmamış suçlar dolayısıyla ilk defa suç işleyen kişiyi hapis cezasına mahkum etmenin ortaya çıkaracağı sakıncaları gidermek için kabul edilmiş bir alternatif yaptırım olarak kabul edilmiştir.

II. Yürürlükten kaldırılan 765 s. TCK'nın sisteminde, suçların “*cürüm*” ve “*kabihat*” olarak ayırımı tabi tutulmasına paralel olarak, para cezaları “*ağır para cezası*” ve “*hafif para cezası*” olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Cürümler için “*ağır para cezası*”, kabahatler için ise “*hafif para cezası*” öngörülmüştü (765 s. TCK, m. 11).

Bu sistemde, kanunda belirlenmiş olan ceza miktarları dikkate alınmadığı gibi, bu miktarlarda yapılan değişiklikler de kabahat türünden bir suçu cürüm veya cürüm türünden bir suçu kabahat olarak nitelendirmeye imkan tanımamaktaydı. Her ne kadar 765 s. Kanunda ağır veya hafif para cezalarının genel olarak alt ve üst sınırları belirlenmiş ise de (“*ağır para cezası*” için m. 19, “*hafif para cezası*” için m. 24); kabahat türünden bir suç için öngörülmüş olan “*hafif para ceza-*

luğu kısıtlaması söz konusu olduğundan, gözaltına almaya Cumhuriyet savcısı, tutuklamaya ise sulh ceza hâkimi karar verecek, gözaltı süresine uyulacaktır. Buna karşılık, buradaki amaç farklı olduğundan, gözaltı ve tutuklama için aranan nedenler ve şartlar burada aranmayacaktır. Kişinin kimliği belirlenir belirlenmez, özgürlüğü kısıtlayıcı işleme son verilecektir.” (5326 s. Kanun, m. 40 gerekçesi).

Bu hürriyetten yoksun bırakma olgusu, tazyik hapsinden ziyade, **kendine özgü** (nevi şahsına münhasır) bir **koruma tedbiri** niteliği taşımaktadır. Bir Hukuk Toplumunda yetkili kamu görevlilerince kim olduğu belirlenemeyen insanların serbestçe dolaşması, kişi güvenliği ve toplum barışı açısından önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Bu amaçla, özel bir koruma tedbiri olarak, kimliği belirlenene kadar kişi gözaltına alınabilecek ve hatta tutuklanabilecektir. Hizmet ettiği amaç dolayısıyla, bu özel koruma tedbirine ilişkin olarak Kanunda bir süre belirlenememiştir. Ancak, bu durumdan, söz konusu koruma tedbirinin sınırsız olarak uygulanabileceği sonucu çıkarılamaz. Mahiyeti itibarıyla, bu koruma tedbiri sınırlı bir süre için uygulanabilir.

sı”nın miktarı, cürüm için öngörölmüş olan “*ağır para cezası*”na nazaran çok daha fazla olabilmekteydi.

Ayrıca, 765 s. TCK’da “**klasik para cezası sistemi**” benimsenmişti. Bu sistemde, (“*ağır*” veya “*hafif*”) para cezası çeşitli şekillerde belirlenebilmektedir.

Birinci yöntemde, bir suçun kanuni tanımında *maktu bir miktar para*, (“*ağır*” veya “*hafif*”) para cezası olarak öngörölmüş olabilir (Örneğin, 765 s. TCK, m. 191, f. 3).

İkinci yöntemde, (“*ağır*” veya “*hafif*”) para cezası, ilgili suç tanımında *alt ve üst sınırları gösterilmek suretiyle* belirlenebilmektedir.

Üçüncü yöntemde, (“*ağır*” veya “*hafif*”) para cezasının ilgili suç tanımında *sa-dece üst sınırı* gösterilmektedir. Bu durumda somut olayda ceza tayin edilirken, “*ağır*” veya “*hafif*” para cezalarının genel olarak belirlenen alt sınırı göz önünde bulundurulur (765 s. TCK, -cürümler için- m. 19, -kabahatler için- m. 24).

Dördüncü yöntemde, (“*ağır*” veya “*hafif*”) para cezasının ilgili suç tanımında *sa-dece alt sınırı* gösterilmektedir. Bu durumda somut olayda ceza tayin edilirken, “*ağır*” veya “*hafif*” para cezalarının genel olarak belirlenen üst sınırı göz önünde bulundurulur (765 s. TCK, -cürümler için- m. 19, -kabahatler için- m. 24).

Bu sistemde ayrıca, (“*ağır*” veya “*hafif*”) para cezası olarak, “*nispî* (veya *misli*) *para cezası*”na yer verilmiştir. Bu durumda, ilgili suç tanımında bir para miktarı gösterilmez; para cezasının miktarı, suçtan sağlanan haksız menfaate veya oluşan zarara göre belirlenmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, 765 s. TCK’nın 19. maddesinde “*ağır*” para cezası ile ilgili olarak belirlenen üst sınırın nispi para cezası açısından geçerli olmadığı, yani nispi para cezasının yukarı sınırının olmadığı açık bir şekilde vurgulanmıştı. Fakat, bu hükmün karşıt anlamından çıkan sonuç şuydu: 765 s. TCK’nın 19. maddesinde “*ağır*” para cezası ile ilgili olarak belirlenen alt sınır, nispi para cezaları açısından da geçerli olacaktır.

Belirtmek gerekir ki, nispi para cezasının öngöröldüğü bir suç dolayısıyla somut olayda para cezasına hükmedilebilmesi için, suçtan elde edilen haksız menfaatin veya oluşan zararın miktarının açık bir şekilde tespit edilmiş olması gerekir.

Aslında nispi para cezası, ceza kanunlarında müsadereenin yaptırım teorisindeki düşüncelere paralel olarak ve ihtiyaca cevap verebilecek şekilde düzenlenmemiş ve özellikle kazanç müsadereesine yer verilmemiş olmasının ortaya çıkardığı eksikliği gidermek amacıyla, kabul edilmiştir²²⁹.

Ancak, nispi para cezası, özellikle suçun mağdurunun belli bir kişi olması durumunda, mağduriyeti gidermenin ötesinde artırıcı bir etki doğurmaktadır. Ör-

²²⁹ Bu sistemde ayrıca, “*tazminat kabilinden para cezası*”na yer verilmekte ve bir para cezasının tazminat kabilinden para cezası olmasına çeşitli sonuçlar bağlanmaktadır (örneğin 765 s TCK, m. 92; genel bilgi için bkz. ÇINAR, Ali Rıza: *Türk Ceza Hukukunda Cezalar*, Ankara, 2005, sh. 82; ÇETİN, Soner Hamza: *Türk Ceza Kanununda Adli Para Cezası*, Ankara, 2012).

neğin dolandırıcılık suçundan dolayı nispi para cezasına hükmolunması halinde, hükümlü açısından bu para cezasını ödenmesi mağdurun mağduriyetini gidermeye nazaran önceliği haiz olmaktadır.

Para cezasına ilişkin klasik sistemin bir sonucu olarak, cezanın belirlenmesi sürecinde artırma ve indirimler, para miktarı üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle, cezanın hesaplanmasında küsürlü rakamlarla karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır.

Ayrıca ülkemizde yaşanan ekonomideki enflasyonist süreçte paranın sürekli değer kaybetmesi karşısında, kanunda ceza olarak belirlenen para miktarlarının artırılmasına yönelik “çare”ler arayışı içine girilmiş ve başvurulmuş her bir “çözüm” yöntemi beraberinde başka birtakım sorunları getirmiştir. Geliştirilen “çözüm” yöntemleri ile Türk hakimî ceza adaletini sağlamaktan ziyade, hesap hatası yapmamaya özen gösterir bir muhasebeci görevini deruhte etmeye başlamıştır. Sonuçta belirlenen para cezası miktarları ceza adaletini sağlama açısından hep kuşkuyla karşılanmıştır.

III. Yeni TCK’da önce, bir ceza hukuku yaptırımı olarak para cezasının adı, adli para cezası olarak değiştirilmiştir²³⁰. Keza bu Kanunda sadece suç kavramına yer verilmiştir. Suçlar, “cürüm” ve “kabahat” olarak bir ayırıma tabi tutulmamıştır. Bu nedenle “ağır para cezası” ve “hafif para cezası” ayırımı terkedilmiştir. Buna karşılık, kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğiliminin bir sonucu olarak kabul edilen 5326 s. *Kabahatler Kanununda*, kabahat karşılığında öngörülen idari yaptırımlardan birini **idari para cezası oluşturmaktadır.**

Kabahatler Kanununun Genel Gereğesinde adli para cezası ile idari para cezası arasındaki ayırıma ilişkin olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

Kabahat niteliğindeki “fiiller karşılığında, genellikle parasal nitelikte bir yaptırım öngörülmektedir. Ancak, bu parasal yaptırım, bir ceza hukuku yaptırımı olan “adli para cezası” değil; idari yaptırım olarak “idari para cezası” niteliği taşımaktadır.

Belirtmek gerekir ki, her ikisi de belli bir miktar paranın kişiden alınıp Devlet Hazinesine intikalinden ibaret gibi görünürse de; adli nitelikteki para cezası ile idari nitelikteki para cezası arasında, karar veren merci, yaptırımın infaz sureti, yaptırıma bağlanan kanunî neticeler bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Örneğin, idari nitelikte bir yaptırım olarak para cezasına, ceza muhakkemesi süreci sonucunda mahkeme tarafından hükmedilmez; bu ceza, idari

²³⁰ Önemle belirtilmek gerekir ki, yeni TCK’nın hazırlanmasında esas alınan yaptırım teorisinde “**ekonomik suça ekonomik ceza**” gibi bir formül kesinlikle **kabul görmemiştir**. “Ekonomik suça ekonomik ceza” formülü, ceza hukuku formülü değildir (Bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Yeni Türk Ceza Kanunundaki Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar*, in: *Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu*, Adalet Bakanlığı/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 30 Nisan-1 Mayıs 2005, Ankara, sh. 73 vd.).

görev yapan bir kişi veya kurul tarafından verilir. Bu cezalar, adli sicile kaydedilmez, ödenmediği takdirde hapse dönüştürülmez.

İdari nitelikteki "para cezası", bir uyarı (ikaz) fonksiyonu gördüğü gibi, kamu açısından oluşmuş olan zararın giderilmesi amacına da hizmet edebilir. Bu nedenle, idari para cezasının misli nitelikte olması mümkündür.”²³¹

Kabahatler Kanununun 17. maddesinde kabahat karşılığında öngörülen idari para cezasının “*maktu veya nispi*” olabileceği (f. 1) ve hatta, “*kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de*” belirlenebileceği (f. 2) hüküm altına alınmıştır.

Yeni TCK’nın sistemine göre; “*suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adli para cezalarıdır.*” (m. 45, f. 1). Söz konusu maddenin gerekçesinde bu hususla ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Bir suç karşılığında kanunda ceza olarak sadece hapis cezası öngörülebileceği gibi, hapis cezası adli para cezası ile seçenek olarak veya bu cezaların her ikisi birlikte de öngörülebilir.”

“Adli para cezası ilke olarak hapis cezası ile birlikte değil bu cezaya alternatif olarak uygulanacaktır. Buna karşılık ekonomik kazanç elde etme amacının güdüldüğü belli suçlarda, kanunda ayrıca gösterilmesi koşuluyla hapis ve adli para cezasına birlikte hükmedilebilecektir.”

Adli para cezası, işlediği suç nedeniyle kusurlu bulunan kişi tarafından belli bir miktar paranın “*Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.*” (m. 52, f. 1; 5275 s. İnfaz K, m. 106, f. 1).

Yeni TCK’da, 765 s. Kanundan farklı olarak, “**gün para cezası sistemi**” kabul edilmiştir.

Bu sistemde, adli para cezasının, *gün* unsuru ve *bir gün karşılığı ödenmesi gereken para* unsuru olmak üzere, iki unsuru bulunmaktadır.

İşlenen suç dolayısıyla Kanunun 61’inci maddesinde cezanın belirlenmesine ilişkin yöntem ve sıra takip edilerek işlenen suç dolayısıyla sonuç gün bulunmalıdır. Bu yöntem ve sıraya ilişkin ayrıntılı açıklamalar, 61’inci madde altında yapılmıştır.

Ayrıca, cezanın bireyselleştirilmesi aracı olarak, kişinin ekonomik durumu ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sayısı ve bunların kendisine yüklediği mali külfet gibi şahsi halleri göz önünde bulundurularak, bir gün karşılığında ödeyebileceği para miktarı takdir edilir.

Bulunan sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen para miktarının çarpılması suretiyle gün para cezası miktarı hesaplanmış olur.

²³¹ Türkiye Büyük Millet Meclis Adalet Komisyonu’nun Kabahatler Kanunu Tasarısına ilişkin 23.3.2005 tarihli ve Esas: 1/993, Karar: 72 sayılı Raporu, TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840.

Böylece, adli para cezasına hükmedilirken, ceza adaleti sağlanabilecektir. Hakimlerimiz, hesaplanmasında maddi hataların sıklıkla yapıldığı bir sistemden ve hesap makinesi yıpratmaktan kurtulmuş olacaktır.

Kanunda adli para cezasının gün unsuru açısından alt ve üst sınırlar belirlenmiştir. Buna göre, adli para cezasının gün unsuru “beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde yediyüzotuz günden fazla” olamaz (m. 52, f. 1).

Bu itibarla, adli para cezasının gün unsurunun üst sınırı kural olarak yediyüzotuz gündür. Bu gün sayısı, ilgili suç tanımında adli para cezasının hapis cezasına seçenek olarak öngörüldüğü durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Bir suç tanımında örneğin “altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası” öngörülmüş ise; mahkemenin, cezanın bireyselleştirilmesi kapsamında takdirini fail hakkında adli para cezasına hükmetme yönünde kullanması durumunda, adli para cezasının üst sınırı yediyüzotuz gün olarak dikkate alınmalıdır.

Ancak, bazı suçlara ilişkin kanuni tanımda adli para cezasının üst sınırı ayrıca belirlenmektedir. Bu sistemde ancak ekonomik çıkar amacına yönelik olarak işlenen bazı suçlarda hapis cezasının yanı sıra adli para cezası öngörülmektedir. Bu suç tanımlarında adli para cezasının üst sınırı ayrıca belirlenmektedir. Yani, ekonomik çıkar amacına yönelik olarak işlenen bazı suçlara ilişkin kanuni tanımlarda, adli para cezasının gün unsurunun *sadece üst sınırı* ayrıca belirlenmektedir.

Ekonomik çıkar amacına yönelik olarak işlenen bazı suçlarda suçun işlenmesi suretiyle bir menfaatin elde edildiği muhakkak görülmekle birlikte, ne kadar gelir elde edildiği bazı durumlarda belirlenememektedir.

Elde edilen gelirin miktarının belli olması halinde, Kanunun *kazanç müsaderesine* ilişkin hükümleri (m. 55) çerçevesinde bu gelirin müsadereci cihetine gidilecektir.

Ancak, elde edilen gelirin miktarının belirlenememesi halinde müsadere kararı vermek mümkün olmayacaktır. İşte bu durum göz önünde bulundurularak, ilgili suç tanımlarında hapis cezasının yanı sıra adli para cezası öngörülmüş ve adli para cezasının üst sınırı ayrıca belirlenmiştir.

Zira, yeni TCK’nın benimsediği temel düşünceye göre; **suç işlemek bir kazanç kaynağı olarak görülemez ve suçtan elde edilen gelir, kişinin yanında kâr olarak kalmaz**²³².

Fakat, yeni TCK’da benimsenen yaptırım teorisine ilişkin bu temel felsefe farklılığına rağmen, eski alışkanlıklarımızın bir yansıması olarak, TBMM’nde kabul edilen örneğin 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı **Bankacılık Kanununda** suç olarak tanımlanan çeşitli fiiller karşılığında *alt ve üst sınırı belirlenmiş hapis*

²³² Yeni TCK’nın bu yöndeki düzenlemesine eleştiri için bkz. İŞOĞLU, Polat: *Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Adli Para Cezası*, Ankara, 2008, sh. 218.

cezasının yanı sıra yine gün olarak *alt ve üst sınırı belirlenmiş adli para cezası* öngörülmüştür.

Kanunda ayrıca, *bir gün karşılığı ödenmesi gereken para* miktarının alt ve üst sınırı da Kanunda belirlenmiştir. TCK’de 2.3.2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanunla (m. 9) yapılan değişikliğe göre, bir gün karşılığı ödenmesi gereken para miktarı, “*en az yüz ve en fazla beşyüz Türk Lirası*” olabilir (m. 52, f. 2). Yukarıda da belirtildiği gibi, bir gün karşılığı ödenmesi gereken para miktarının belirlenmesi, cezanın bireyselleştirilmesi enstrümanıdır. Bu itibarla, kişinin ekonomik durumu ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sayısı ve bunların kendisine yüklediği mali külfet gibi şahsi halleri göz önünde bulundurularak, bir gün karşılığında ödeyebileceği para miktarı bu alt ve üst sınır arasında takdir edilir.

Bu alt ve üst sınır arasındaki makasın genişliğinin, toplumu oluşturan bireyler arasındaki gelir dağılımı göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiği muhakkaktır. Ancak, bir sistem değişikliğinin söz konusu olduğu bu düzenlemelerde, özellikle eşitlik ilkesi bağlamında maruz kalınabilecek eleştiriler²³³ göz önünde bulundurularak bu makas başta dar tutulmuştur. Sistemin hukuk çevrelerimizde benimsenmesi durumunda, yapılacak bir kanuni düzenlemeyle, bir gün karşılığı ödenmesi gereken para miktarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenebilir²³⁴.

Adli para cezasının belirlenmesine ve bireyselleştirilmesine ilişkin yöntem ve süreç, 61’inci madde bağlamında izah edilmiştir²³⁵.

Yeni TCK’da gün para cezası sistemi kabul edildiği için, bu sistemde **nispi para cezasına yer verilmemiştir**. Aslında nispi para cezası, ondokuzuncu yüzyıl ceza kanunlarında yer alan müsadereye ilişkin hükümlerin yetersizliğini izale etmek ve özellikle kazanç müsaderesine yer verilmemesinin ortaya çıkardığı boşluğu doldurmak amacıyla kabul edilmişti.

Yeni TCK’da özellikle kazanç müsadereyi ayrıntılı bir şekilde düzenlendiğine göre, ayrıca çeşitli suç tanımları bağlamında ayrıca nispi para cezasının öngörülmesine gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, nispi para cezasının kabulü, bazı durumlarda suçun mağduru aleyhine sonuç doğurmaktadır. Örneğin 765 s. TCK’nın sisteminde dolandırıcılık suçuyla ilgili olarak nispi para cezası öngörülmüştü: Nitelikli dolandırıcılık suçunda, kişinin “*sağladığı haksız menfaatin iki misli kadar ağır para cezası*” (m. 504, f. 1). Bu düzenleme dolayısıyla, dolandırıcılık suçundan mahkum olan kişi için, mahkum edildiği nispi nitelikteki “ağır para cezası”nın

²³³ Bu yönde eleştiri için bkz. BAYRAKTAR, Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Genel Bir Değerlendirme ve Genel Hükümler Üzerine Birkaç Eleştiri, sh. 34 vd.

²³⁴ Bu yönde eleştiri için bkz. ÇINAR, Türk Ceza Hukukunda Cezalar, sh. 91.

²³⁵ Çınar’ın bu konudaki açıklamalarında hatalar bulunmaktadır (ÇINAR, Türk Ceza Hukukunda Cezalar, sh. 87, 92).

ödenmesi, bu suçu işlemekle mağdur ettiği kişinin mağduriyetini gidermeye nazaran önceliği haiz olmaktadır.

Fakat, yeni TCK'nın 158. maddesinin birinci fıkrasına 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla aşağıdaki şekilde bir cümle eklenmiştir:

*“Ancak, (bu maddenin) (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, **adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.**”*

Madde metninde yapılan bu değişikliğe ilişkin **gerekeçde** şu açıklamaya yer verilmiştir:

“Maddenin birinci fıkrasında sayılan nitelikli dolandırıcılık hallerinden (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan suçların işlenmesi halinde verilecek hapis cezasının alt sınırının üç yıldan az olamayacağı, yine bu hallerde verilecek adli para cezasının miktarının suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacağı hükme bağlanmaktadır.

Bu değişikliğe göre, suçtan elde edilen gelir miktarının belli olması halinde de adli para cezasına hükmedilecektir. Ancak, Kanunun 52 ve 61'inci maddeleri hükümlerine göre hükmedilecek adli para cezasının miktarı, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır. Yapılan değişiklikle madde metnine eklenen hükme göre, suç tanımında belirlenen günün üst sınırından hesaplanan adli para cezasının miktarının, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmaması gerekmektedir. Bu itibarla, suçun işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin fazla olması halinde, madde metnindeki adli para cezasının unsurunu oluşturan gün bakımından getirilen sınırlamanın bir önemi kalmayacaktır.”²³⁶

Bu hüküm, ülkemizde yaşanan banka kaynaklarının zimmete geçirilmesi olaylarıyla bağlantılı olarak madde metnine eklenmiştir. Bu değişiklik, bir davada banka kaynaklarının zimmete geçirilmesi dolayısıyla ilgililer hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan (765 s. TCK, m. 504) dolayı verilen mahkumiyet kararının yeni TCK'nın hükümlerinden etkilenmemesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Aslında yeni TCK'nın kazanç müsadereğine ilişkin hükümleri karşısında, bu maddede bir değişiklik yapılmasına gerek yoktu. Zaten bu hüküm, yeni TCK'nın yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihine kadar kanunlaşarak yürürlüğe konmadığı için; madde metninde yapılan bu değişikliğin, ilgili mahkumiyet kararı açısından bir önemi de kalmamıştır.

Yeni TCK'nın benimsediği yaptırım sisteminde **nispi para cezasına yer verilmemiş** olmasına rağmen; daha sonra çıkarılan çeşitli kanunlarda yer alan suç tanımları bağlamında nispi nitelikte para cezası hala varlığını muhafaza etmektedir.

²³⁶ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 4.

Örneğin, 5411 s. **Bankacılık Kanununda** yer alan özel nitelikteki zimmet suçunun nitelikli haliyle ilgili olarak nispi nitelikte adli para cezası öngörülmüştür:

“Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası verilir; ancak, adli para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın üç katından az olamaz.” (m. 160, f. 2; ayrıca bkz. f. 3).

Aslında bu düzenlemede, gün para cezası sistemiyle nispi nitelikteki para cezası sistemi bir ölçüde birbirleriyle telif edilmeye çalışılmıştır. Ancak, buna rağmen, söz konusu düzenleme, nispi nitelikteki para cezası sisteminin mahzurlarını taşımaya devam etmektedir.

765 s. Kanundan farklı olarak, yeni TCK’nın sisteminde, **adli para cezasının ertelenmesi söz konusu değildir.**

Kural, “kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır” olduğuna göre; işlenen birden fazla suç dolayısıyla birden fazla adli para cezasına mahkumiyet halinde, her bir suçtan dolayı mahkum olunan adli para cezası bağımsızlığını koruyacaktır. Bu cezaların hepsi, ayrı ayrı infaz edilmek gerekir.

Yeni TCK’da gün para cezası sistemine geçilmiş ise de, bu Kanununu yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mer’i diğer kanunlarda yer alan suç tanımlarındaki para cezaları klasik para cezası sistemine göre belirlenmiştir. Bu kanunlarda gün para cezası sistemine uygun gerekli değişiklikler yapılmaya kadar, klasik para cezası sisteminin işlerliğinin sağlanması gerekmiştir. Bu düşüncelerle, ve 5252 sayılı **Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda** geçiş dönemine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır (m. 4, 5)^{237,238}.

IV. Mahkeme, fail hakkında adli para cezasına hükmederken, bu cezayı taksite bağlayabilir:

“Hâkim, ekonomik ve şahsî hâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde ödemesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.” (m. 52, f. 4)²³⁹.

²³⁷ Bu geçiş hükümlerine ilişkin açıklamalar hakkında Kitabımızın 11. ve daha önceki basılarına bakılabilir.

²³⁸ 5252 s. Yürürlük Kanunuyla, 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlüğe giren bütün kanunlardaki “hafif hapis” ve “hafif para” cezaları, idari para cezasına dönüştürülmüştür (m. 7).

²³⁹ “Mahkemece adli para cezasının taksitlendirilmesine karar verilirken esas alınması gereken kanuni ölçüt **sanığın ekonomik durumu ve şahsi halidir**. TCK’nın 52/2. maddesi uyarınca gün adli para cezasının bir gün karşılığı ödenmesi gereken para miktarının belirlenmesinde de

V. 5275 sayılı İnfaz Kanununun ilk düzenlemesinde, **adli para cezasının ödenmemesi halinde**, hükümlünün tazyik (zorlama) hapsine tabi tutulması yönünde hükümlere yer verilmişti. Yani kişi adli para cezasını ödemediği takdirde bu parayı ödemeye zorlanmak için mahkum olduğu adli para cezasının gün birimi esas alınarak parayı ödeyinceye kadar ve her halde üç veya beş yılı geçmemek üzere zorlama hapsine tabi tutulması gerekiyordu²⁴⁰.

Ancak, infaz kurumlarındaki koşullar dikkate alınarak, adli para cezasının ödenmemesi halinde tazyik hapsi yerine, hükümlünün kamuya yararlı bir işte çalışmasına da karar verilebilmesi yönünde öneride bulunmuş idik²⁴¹. Bu önerimize göre, kişi mahkûm olduğu adli para cezasına ilişkin olarak mahkûmiyet hükmünde gün birimi olarak belirlenen sonuç gün sayısı kadar bir süreyle kamuya yararlı bir işte çalıştığı takdirde, adli para cezası infaz edilmiş sayılmalıdır. Bu sistemde, **kamuya yararlı bir işte çalışılan her bir gün, adli para cezasının hesaplanmasında dikkate alınan gün birimindeki bir güne tekabül etmelidir**.

Nispi para cezası veya genel olarak klasik para cezası yöntemiyle belirlenmiş olan adli para cezasının ödenmemesi halinde ise; hükümlünün, *Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında* 4.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı Kanunun 5. maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen ölçü dikkate alınarak, mahkûmiyet hükmünde adli para cezası olarak hükmolunan miktarın her yüz TL'lik kısmı karşılığında bir gün kamuya yararlı işte çalışması sağlanarak, bu cezanın infazı yoluna gidilebilmelidir.

Dikkat edilmelidir ki, bu sistemde, kamuya yararlı bir işte çalışma bir yaptırım değildir. Aksine, yaptırım olan adli para cezasının infazı bağlamında yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak telakki edilmelidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde, çalışılan her bir gün karşılığında adli para cezası in-

esas alınan bu ölçütlerden, sanığın ekonomik durumundan anlaşılması gereken, sanığın mal varlığı, gelir ve sabit giderlerinin miktarı, şahsi halinden anlaşılması gereken ise medeni durumu ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi ekonomik durumunu etkileyen diğer halleridir. Adli para cezasının taksitlendirilmesinde esas alınan bu ölçütler tamamen sanığın ekonomik ve şahsi durumu ile alakalı olup işlenen suçla, sanığın ekonomik ve şahsi durumu dışında kalan diğer halleri ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu ölçütlerin amacı **cezanın bireyselleştirilerek** suç işleyen farklı maddi durumdaki kişiler arasındaki eşitsizliği gidermektir.

Hakim, ekonomik durumu ve şahsi hali ile ilgili en iyi bilgi sahibi olan sanığın bu husustaki taleplerini dikkate alarak infaz aşamasında taksitlendirme imkanının bulunduğunu da gözetip, belirtilen ölçütler kapsamında değerlendirme yapmalı ve kanunun o suç için öngördüğü adli para cezası tercihini veya hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini anlamsız kılmayacak biçimde taksitlendirme konusunda bir karar vermelidir. Bu konuda hakimin isabetli bir karar verebilmesi için sanığın ekonomik durumu ve şahsi hali ile ilgili takdire yetecek ölçüde bilgi sahibi olması gerekir. Nitekim, CMK'nın 147/1-g maddesinde asgari oranda bunu sağlamaya yönelik olarak, ifade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınacağı öngörülmüştür." CGK, 17.9.2013, E. 2012/12-1522, K. 2013/373.

²⁴⁰ Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için Kitabımızın 9. ve daha önceki basılarına bakılabilir.

²⁴¹ Bu konuda Kitabımızın 9. basısına bakılabilir.

faz edilmiş kabul edilecektir. Bu yükümlülüğün gereklerinin yerine getirilmemesi halinde ise, adli para cezasının tazyik hapsi uygulanmak veya 6183 s. *Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun* hükümlerine göre cebrî icra yoluyla tahsil edilmek suretiyle infazı sağlanmalıdır.

Adli para cezasının infazı bağlamında kamuya yararlı işte çalışmaya karar verme yetkisi, bu cezanın infazını gerçekleştirmekle görevli olan Cumhuriyet savcısına verilmelidir.

Söz konusu düşüncelerimiz kısmen dikkate alınarak, İnfaz Kanununun 106. maddesinde **18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla**, aşağıda açıklandığı üzere, değişiklik yapılmıştır.

XIV. Cezaların İnfazı

A. Genel Olarak

İnfaz, işlenen **suç** dolayısıyla hükmolunan ve kesinleşen ceza hukuku yaptırımlarının uygulanması sürecini ifade etmektedir. Buna karşılık, **icra** ise, özel hukuk yaptırımlarının yerine getirilmesi sürecini ifade etmektedir. Keza, idari yaptırımlar bağlamında da infaz değil, “yerine getirme” ibaresi kullanılmıştır (5326 s. Kabahatler Kanunu, m. 18, f. 1; m. 21).

Hangi alanda olursa olsun, yaptırımların uygulanma süreçlerinin ortak özelliği, gerektiğinde devlet gücünün kullanılmasıdır. Bu itibarla, yaptırımların uygulanması bağlamında **hukukun cebrîlik vafından** söz edilir. Yaptırımın uygulanması sürecinde devlet gücünün kullanılması zorunlu değildir. Kişi yaptırımın gereğini iradi olarak yerine getirdiği takdirde, kamu gücünün kullanılmasına gerek olmaz. Ancak, kişi, yaptırımın gereğini yerine getirmekten imtina ederse, kamu gücünün kullanılması söz konusu olur.

“İnfaz” ibaresi, kural olarak ancak suç teşkil eden haksızlıklar karşılığında hükmolunan ceza hukuku yaptırımlarının uygulanması süreci bağlamında kullanılmaktadır. Bu itibarla, **ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazından** söz edilebilir. Keza, belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamaya yönelik olarak mevzuatımızda “disiplin hapsi” veya “tazyik hapsi” hükümlerine yer verilmiştir. Bu yaptırımların uygulanması bağlamında da infaz ibaresi kullanılmaktadır (İnfaz Yönetmeliği²⁴², m. 145).

²⁴² İnfazla ilgili hususlar 5275 sayılı infaz Kanununda düzenlendiği gibi, Bakanlar Kurulu’nun 20.3.2006 tarih ve 2006/10208 sayılı Kararı ile kabul edilen “*Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük*”te de **mükerreren** düzenlenmişti. Ancak, bu Tüzük, Cumhurbaşkanlığı’nın 28.3.2020 tarihli ve 2324 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılarak, yerine “**Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik**” (RG: 29 Mart 2020/31083) kabul edilmiştir (kısaca, **İnfaz Yönetmeliği** olarak anılacaktır).

Buna karşılık, ceza muhakemesi hukukundaki koruma tedbirleri yaptırım olmadığı için, bunların infazından değil, yerine getirilmesinden, uygulanmasından ve genel olarak, icrasından söz edilir. Elkoyma kararının yerine getirilmesi, uygulanması, icrası gibi. Ancak, mevzuat temeli olmamakla birlikte, hukuk uygulamamızda bazen tutuklamanın “infazı”ndan söz edildiğine tanık olunmaktadır. Bunun sebebi, uygulamamızda tutuklamanın bir “ön cezalandırma” yöntemi olarak kullanılmasıdır. Oysa İnfaz Yönetmeliğinde tutuklama kararıyla ilgili olarak da “*yerine getirme*” ibaresi kullanılmıştır (m. 135).

Koruma tedbirleriyle yaptırımlar arasındaki ortak özelliğin, uygulanma sürecinde gerektiğinde kamu gücünün kullanılması olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

Bir kişi hakkında cezaya hükmedilmiş olsa bile, bu hüküm kesinleşmedikçe kişi hükümlü statüsünü kazanmaz. Başka bir ifadeyle, hapis veya adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün kesinleşmesiyle kişi hükümlü statüsünü kazanmaktadır. Kişi hakkında hükmolunan ceza ve güvenlik tedbirleri, ancak **mahkumiyet hükmü kesinleştikten sonra infaz** edilir (İnfaz K, m. 4; İnfaz Yönetmeliği, m. 4, f. 1).

Cezaya veya güvenlik tedbirine ilişkin mahkumiyet hükmü kesinleştikten sonra, hükmü veren mahkeme tarafından infaz için ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir (İnfaz K, m. 5; m. 20, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 4, f. 2)²⁴³.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı, “*Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.*” (İnfaz K, m. 5).

Söz konusu Yönetmeliğin varlığı, yürürlükten kaldırılan Tüzük gibi, **gereksiz** ve hatta **sakıncalıdır**. İnfaz Kanununda zamanla değişiklik yapılmasına rağmen, İnfaz Yönetmeliğinde konuyu düzenleyen hükümlerinde paralel değişiklikler zamanında yapılmamaktadır. Örneğin 14.4.2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunla İnfaz Kanununun çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmış olmasına rağmen, bu değişiklikler İnfaz Yönetmeliğine henüz yansıtılmamıştır. Bu nedenle Kanunla Yönetmelik hükümleri arasında zaman içerisinde önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu durum, İnfaz Yönetmeliğinin içerdiği düzenlemelere, uygulayıcılar bakımından tereddüt oluşturan ve hatta yanılgıya sevk eden bir mahiyet kazandırmaktadır.

²⁴³ Hangi yer Cumhuriyet savcısının infazla yetkili olduğu hususunda Kanunda ve sair mevzuatta açıklık yoktur. Bu bağlamda;

- 1) Kesinleşen hükmü veren mahkemenin yargı çevresindeki Cumhuriyet Başsavcılığında infazla görevli Cumhuriyet savcısı,
- 2) Hükümlünün ikametgahının bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığında infazla görevli Cumhuriyet savcısı,
- 3) Hükümlünün fiilen bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığında infazla görevli Cumhuriyet savcısı, akla gelebilir. Şayet hükümlünün Türkiye’de ikametgahı (yerleşim yeri) mevcut ise, bu yer Cumhuriyet Başsavcılığında infazla görevli Cumhuriyet savcısının; ancak, hükümlünün Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa, örneğin yabancı ise, Türkiye’de fiilen bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığında infazla görevli Cumhuriyet savcısının, bu bağlamda yetkili olduğunu kabul etmek gerekir.

Atalay, kesinleşmiş mahkumiyet kararının (ilamın), “verildiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına” gönderilmesi gerektiğini belirtir (ATALAY, Osman: *İnfaz Hukuku ve İlamların İnfazı*, Ankara, 2015, sh. 19).

Hükmolunan cezalar ile güvenlik tedbirleri, Cumhuriyet başsavcılığınca **infaz defterine** kaydedilir (İnfaz K, m. 20, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m. 47, f. 2, bent a; m. 50; m. 52, f. 1, bent a; m. 53, f. 2, bent a).

B. Hapis Cezasının İnfazı

Hapis cezasına mahkum olan hükümlü ile ilgili ceza, yukarıda belirtildiği gibi, **mahkumiyet hükmü** ile birlikte bu mahkumiyet kararının **kesinleşme şerhi**-nin²⁴⁴ mahkemece gönderilmesi üzerine, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından **infaz defterine kaydedilir**. Bu kayıt işlemi **geciktirilmeksizin** yerine getirilir (İnfaz Yönetmeliği, m. 54, f. 2). Bu kayıt işlemi müteakip, Cumhuriyet başsavcılığı hükümlü ile ilgili olarak “**çağrı kâğıdı veya yakalama emri**” çıkarır (İnfaz K, m. 20, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m. 54, f. 2)^{245, 246}.

Çağrı kâğıdı, **hükümde gösterilen adrese** tebliğ edilir (İnfaz K, m. 20, f. 3; İnfaz Yönetmeliği, m. 144, f. 1)²⁴⁷.

Hükümlünün, gönderilen çağrı kâğıdının tebliği üzerine **on gün** içinde gelmemesi²⁴⁸, kaçması ya da kaçacağına dair şüphe uyandırması halinde; hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından **yakalama emri** çıkarılır (İnfaz K, m. 19, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 54, f. 4).

Ancak belirtmek gerekir ki, hükümlü hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılmasında, hükümlünün mahkum olduğu **ceza miktarı** göz önünde bulundurulur:

²⁴⁴ Bu şerhte,

“a) Mahkûmiyetin hangi hükümlü hakkında verildiği ve hangi ceza veya tedbirin infazına ilişkin olduğu,

b) Kararın kesinleşme şekli ve tarihi,

c) Cumhuriyet başsavcılığına infaz için kararın gönderiliş tarihi,

d) Mahkûmiyet kararı birden çok hapis cezasını içeriyorsa;

1. Süreli hapis cezalarında bunların toplamı,

2. Süreli hapis cezası, müebbet hapis cezası veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında bunlardan hangilerinin infaz edileceği,

gösterilir.” (İnfaz Yönetmeliği, m. 54, f. 1).

²⁴⁵ Bütün bu konulara ilişkin bilgi için bkz. ATALAY, sh. 19 vd.

²⁴⁶ “Hakkında yakalama emri çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi amacıyla gerektiğinde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilmesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanununun 119’uncu maddesi hükümleri uygulanır. Hâkim tarafından verilecek arama kararları sulh ceza hâkimi tarafından verilir.” (İnfaz K, m. 19, f. 4).

²⁴⁷ “Hükümlü, adres değişikliklerini mahkemeye veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle yükümlüdür. Aksi hâlde hükümde gösterilen adreste yapılan tebligat geçerlidir.” (İnfaz K, m. 20, f. 3. Ayrıca bkz. İnfaz Yönetmeliği, m. 144, f. 1).

²⁴⁸ Çağrı kâğıdı üzerine hükümlü, infaz için, çağrıda bulunan Cumhuriyet Başsavcılığına veya “kendisine en yakın” Cumhuriyet Başsavcılığına başvurur (ATALAY, sh. 21).

“*Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla hapis cezasının infazı için doğrudan (yani çağrı kâğıdı gönderilmeden) yakalama emri çıkarılır.*” (İnfaz K, m. 19, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m. 54, f. 4).

Çağrı kâğıdına icabet ederek Cumhuriyet başsavcılığına başvuran veya yakalama emri üzerine yakalanan hükümlü, Cumhuriyet başsavcılığının emriyle **infaz kurumuna konulur** (İnfaz K, m. 20, f. 1).

Hükümlünün hangi ceza infaz kurumuna gönderileceği hususunda mevzuatımızda açık hüküm bulunmamaktadır. Bu durum karşısında, hükümlü,

a) cezasının infazı için başvuruda bulunduğu,

b) yakalandığı,

yer Cumhuriyet başsavcılığına bağlı infaz kurumuna gönderilir.

Ceza infaz kurumuna alınan hükümlüye, Cumhuriyet başsavcılığınca, hapis cezasının süresini, bu cezaya hükmeden mahkemenin karar tarih ve sayısını, hangi suç nedeniyle hükmedildiğini, cezanın infazına başlandığı tarihi, hükümlünün koşullu salıverileceği muhtemel tarihi ve bihakkın tahliye tarihini, yani hapis cezasının infazının tamamlanacağı tarihi belirten bir belge verilir (İnfaz K, m. 20, f. 4)²⁴⁹. Bu belgeye, İnfaz Yönetmeliğinde “**süre belgesi**” (m. 54, f. 3), uygulamada ise “**müddetname**” denmektedir²⁵⁰.

İnfaz kurumuna getirilen hükümlü, üstü ve eşyası arandıktan sonra, “*kabul odası*”na alınır (İnfaz K, m. 21, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 55, f.5)²⁵¹.

²⁴⁹ İnfaz Yönetmeliğine göre, “*bu belgede hükümlünün:*

- a) *Kimlik, tebligat ve iletişim bilgileri,*
 - b) *İnfaz defteri numarası,*
 - c) *Kuruma alındığı tarih,*
 - d) *Tutuklulukta veya göz altında geçirdiği süre,*
 - e) *Ceza süresi, hakederek ve koşullu salıverileceği tarih,*
 - f) *Cezanın hangi hükme ilişkin olduğu,*
- belirtilir.*” (m. 54, f. 3).

²⁵⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz. ATALAY, sh. 38 vd.). Müddetnameye itiraz mümkündür. Bu itiraz, hükmü veren veya muadili ceza mahkemesince değerlendirilip karara bağlanmalıdır (11.12.1967 tarihli ve 2/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı; ATALAY, sh. 26 vd.).

²⁵¹ En fazla üç gün tutulabileceği bu odada hükümlü ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır:

Hükümlüler kuruma kabul edilirken kurum hekimi veya aile hekiminden; bunların bulunmaması durumunda hastaneden alınacak sağlık durumunu belirleyen mahsus rapor ile birlikte kuruma kabul edilir (İnfaz Yönetmeliği m. 55, f. 2).

Hükümlünün adı ve soyadı, işlediği suç veya suçlar, mahkum olduğu hapis cezasının veya cezalarının türü ve süresi, mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün “*hükümlü defteri*”ne kayıt olunur. Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur (İnfaz K, m. 21, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m. 55, f. 3).

İnfaz kurumuna kabul edilen hükümlünün parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir, kan grubu, vücudunun dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Bu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır. Bu bilgiler, Kanunda belirtilen haller

C. Hükümlülerin Tasnifi

İnfaz kurumuna kabul edilen hükümlüler, gözlem uygulaması sonucunda belirli kriterler itibarıyla tasnife tabi tutulur^{252,253}.

dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez (İnfaz K, m. 21, f. 3; İnfaz Yönetmeliği, m. 55, f.4, bent a).

İnfaz kurumuna kabul edilen hükümlü, cezaevi tabibi tarafından muayene edilir (İnfaz K, m. 21, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 55, f.5, bent b). Bu muayenede hükümlünün **kurumda tedavisi mümkün olmayan veya bulaşıcı bir hastalığı veya cezasının infazına engel herhangi bir maluliyeti tespit edilirse, durum derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir** (İnfaz Yönetmeliği, m. 55, f. 5, bent c).

Hükümlünün okuma, yazma bilip bilmediği, öğrenim durumu, bir meslek ve sanatı olup olmadığı ve ayrıca, “psiko-sosyal” özellikleri tespit edilir (İnfaz Yönetmeliği, m. 55, f. 5, bent d ve e).

Hükümlüye, kurumda çekilmiş fotoğrafı bulunan bir “*hükümlü kimlik belgesi*” verilir (İnfaz Yönetmeliği, m. 55, f. 5, bent g).

Kabul odasından suç grubuna uygun odaya gönderilmeden önce hükümlünün yıkanması sağlanır (İnfaz Yönetmeliği, m. 55, f. 5).

Hükümlünün ceza infaz kurumuna alındığı, istemesi halinde, ailesine veya gösterdiği bir kişiye bildirilir. Hükümlü yabancı ise, kendisine sorulması üzerine aksi yöndeki iradesini yazılı olarak bildirmediği takdirde, durum vatandaşı bulunduğu devletin en yakın konsolosluğuna bildirilir (İnfaz K, m. 22, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m. 56, f. 3, 4, 5).

İnfaz kurumuna kabul edilen hükümlünün askerlik yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken bir kişi olduğunun anlaşılması halinde, durum kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine bildirilir (İnfaz K, m. 22, f. 3; İnfaz Yönetmeliği, m. 56, f. 6).

²⁵² İnfaz kurumuna kabul edilen hükümlüler,

- “*kişisel özellikleri*”,
- “*bedensel, aklî ve sağlık durumları*”,
- “*suç işlemekten önceki yaşamları*”,
- “*sosyal çevre ve ilişkileri*”,
- “*sanat ve meslek faaliyetleri*”,
- “*ahlâkî eğilimleri*”,
- “*suça bakış açıları*”,
- “*hükümlülük süreleri ve suç türleri*”,

esas alınarak, infaz kurumlarına yerleştirilmektedirler (İnfaz K, m. 23, f. 1, bent a; Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik m. 6, f. 1).

Bu belirleme, “*gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya kapalı ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yapılır.*” (İnfaz K, m. 23, f. 1, bent a; Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, m.4, f. 2).

Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde, yargısal, sosyal, tıbbi, kriminolojik, psiko-teknik, psikiyatri ve ceza hukuku bakımından veya gerekli görülecek konularda her türlü inceleme yapılır. (Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, m. 6, f. 2).

“*Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca kuruma kabul tarihinden başlayarak tek kişilik odalarda yapılır. Ancak kurumun tek kişilik odası bulunmaması veya kısıtlı sayıda olması durumunda tahsis edilmiş özel bölümlerinde de yapılabilir.*” (İnfaz K, m. 23, f. 1, bent d; Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, m. 9).

“*Kadın, çocuk ve genç hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma, gerekli görülen yer veya bölgelerdeki ayrı gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya bunların noksanlığı hâlinde kadın, çocuk ve kadın ve erkek gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yerine getirilir.*” (İnfaz K, m. 23, f. 1, bent c).

Bu belirleme itibarıyla, “*hükümlüler, işledikleri suç tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranışları nedeniyle sıkı gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekir gerekmediğine göre yüksek güvenli keza infaz kurumlarına veya normal güvenli keza infaz kurumlarına veya açık keza infaz kurumlarına gönderilirler.*” (İnfaz K, m. 23, f. 1, bent a; Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik [RG: 29 Aralık 2020/31349], m. 6)^{254, 255}.

²⁵³ Gözlem uygulaması, **iki yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına** mahkum olan hükümlülerle ilgili olarak yapılır:

“*Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkum olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için Kanunda gösterilen esaslar uyarınca gözleme tâbi tutulurlar.*” (İnfaz K, m. 23, f. 1, bent e; Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, m. 6).

Gözlem süresi **altmış günü** geçemez. (İnfaz K, m. 23, f. 1, bent e). Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik m. 9, f.1). Hükümlü, ilk gözlem sonunda yapılan yerleştirme işlemlerine müteakiben kurumda kaldığı süre boyunca gözlemlenir ve gösterdiği gelişim en geç altı ayda bir idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirilir. Ancak bulunduğu keza infaz kurumunda kalacağı süre altmış günden az olan hükümlüler hakkında ilk gözlem kararı alınmaz (Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, m. 9, f.4) Hükümlü, kişisel özellikleri dikkate alınarak ilk gözleme tabi tutulmayabilir (İnfaz K, m. 23, f. 1, bent f; Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik m.10).).

²⁵⁴ “Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı görüşü ile birlikte Adalet Bakanlığına gönderir. Gözlem sonucuna göre **hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça belirlenir**. Ancak, yapılan gözlem ve sınıflandırma sonunda idare ve gözlem kurulunca **aynı keza infaz kurumunda** veya **o yer Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı diğer keza infaz kurumlarında** kalması uygun bulunan hükümlülerin dosyaları Bakanlığa gönderilmez ve cezalarının infazına, bulundukları veya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecekleri bağlı keza infaz kurumlarında devam olunur.” (İnfaz K, m. 23, f. 1, bent g; Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, m. 12, f.1).

²⁵⁵ Hükümlülerin infaz kurumlarına yerleştirilmesinde, aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır:

- a) *Hükümlü kadın ve erkekler, mümkün olduğu kadar ayrı kurumlarda bulundurulur. Aynı kurumda barındırılmaları zorunlu ise, kadın ve erkeklere ait bölümler birbirlerinden tamamen ayrılır,*
- b) *Hükümlü çocuklar ve gençler öncelikli olarak kendilerine ait kurumlarda, mümkün olmadığı takdirde diğerlerinden tamamen ayrı bölümlerde barındırılır,*
- c) *Hükümlüler, tutuklulardan ayrı kurumlarda veya tamamen ayrı bölümlerde bulundurulur,*
- d) *Genel kolluk hizmetlerinde veya diğer kamu görevlerinde çalışmış hükümlüler, kurumların ayrı bir bölümünde barındırılır,*
- e) *Cinsel yönelimi farklı hükümlülerin diğerlerinden ayrı odalarda kalmaları sağlanır.”* (İnfaz Yönetmeliği, m. 57, f. 1)

Hükümlüler, bulundukları veya gönderildikleri kurumlarda; aşağıdaki şekilde gruplandırılır (İnfaz Kanunu, m. 24):

- a) *İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek edinenler,*
- b) *Zihinsel ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine tâbi tutulması gerekenler,*

Ç. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler

“Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir.” (İnfaz K, m. 9, f. 1)^{256, 257}

Hükümlülerden;

- a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar,
- b) Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek suçundan (TCK, m. 220, f. 1) dolayı, süresi ne olursa olsun, hapis cezasına mahkum olanlar,
- c) Devletin güvenliğine veya Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek ya da bu örgüte üye olmak suçlarından (TCK, m. 314) dolayı, süresi ne olursa olsun, hapis cezasına mahkum olanlar,

cezalarını **yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda** çekerler (İnfaz K, m. 9, f. 2).

Ayrıca, suç işlemek amacıyla kurulmuş ve TCK’nın 220. maddesi kapsamına giren bir örgütün faaliyeti çerçevesinde belirli suçları işlemekten dolayı, süresi ne olursa olsun, hapis cezasına mahkum olanlar da cezalarını bu kurumlarda çekerler. Buna göre,

- a) İnsanlığa karşı suçlardan (TCK, m. 77, 78),
- b) Kasten öldürme suçlarından (TCK, m. 81, 82),
- c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (TCK, m. 188),
- d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (TCK, m. 302, 303, 304, 307, 308),

c) Tehlike hâli taşıyanlar,

ç) Terör suçluları,

d) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular,

e) Gözlem sürecinin devamına karar verilenler,”

(Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, m.19 ilâ 24).

²⁵⁶ Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları kapalı ceza infaz kurumlarının bir türüdür. Bu kurumların, kapalı ceza infaz kurumlarından farkı, odalarda bir veya üç hükümlünün bulunduğu ve iyileştirme yöntemlerinin toplumsal değil, bireysel veya grup halinde uygulanmasıdır (bkz. İnfaz Kanunu 9. madde gerekçesi).

²⁵⁷ Ülkemizde genel olarak kapalı ceza infaz kurumları, yapısal özellikleri itibarıyla A tipi, B tipi, D tipi, E tipi F tipi gibi grupları ayrılmıştır.

e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (TCK, m. 309, 310, 311, 312, 313, 315),

birini suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemekten dolayı, süresi ne olursa olsun, hapis cezasına mahkum olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir (İnfaz K, m. 9, f. 2).

İşlediği suç veya mahkum olduğu ceza itibarıyla yüksek güvenlikli infaz kurumunda cezasını çekmesi gerekmesine rağmen, ilgili kanun hükümlerine göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan hükümlüler, ceza süresine bakılmaksızın, Bakanlık onayı ile diğer kurumlarda barındırılabilir (İnfaz Yönetmeliği, m. 5, f. 4).

D. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler

*“**Kapalı ceza infaz kurumları**, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir.”* (İnfaz K, m. 8, f. 1)^{258, 259}.

Kural olarak, işlediği;

- bir kasıtlı suçtan dolayı üç yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,
- birden fazla kasıtlı suçtan dolayı toplamda üç yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,
- bir taksirli suçtan dolayı beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,
- birden fazla taksirli suçtan dolayı toplamda beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

cezalarını kapalı ceza infaz kurumunda çekmeye başlarlar (Bkz. İnfaz K, m. 14, f. 2, bent a ve b).

Ancak, *“Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı*

²⁵⁸ Kapalı ceza infaz kurumlarında oda ve koridor kapıları kapalı tutulur. Kapılar; doktora, revire hamam veya berbere gitme ya da başka odaya veya kuruma nakiller sırasında, eğitim, ziyaretçi ve avukatla görüşme, tahliye, duruşmaya gitme, hastaneye sevk, işyurdunda çalışma, kurullara çağırılma gibi hâllerde, bunlar dışında cezaevi idaresinin gerekli gördüğü durumlarda ve ölüm, deprem veya yangın gibi olağanüstü hâllerde açılır (İnfaz K, m. 34, f. 1). Hükümlüler kapının açık olduğu zamanlarda birbirleriyle temas edebilir, iletişime geçebilirler. Hükümlülerin yukarıda sayılan hâller dışında diğer odalardaki hükümlüler ve kurum görevlileri ile temasta bulunmaları ise hukuken mümkün değildir (İnfaz K, m. 34, f. 2).

²⁵⁹ Bu infaz kurumları da kendi içinde **“Kadın kapalı ceza infaz kurumları”** (İnfaz K, m. 10), **“Çocuk kapalı ceza infaz kurumları”** (İnfaz K, m. 11) ve **“Gençlik kapalı ceza infaz kurumları”** (İnfaz K, m. 12) şeklinde bir ayırıma tabi tutulmuştur.

Belirtmek gerekir ki, *“cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamış”* hükümlüler, **“genç hükümlü”** kabul edilmektedir (İnfaz K, m. 12, f. 1).

işlenen suçlardan mahkûm olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler” mahkum oldukları cezanın süresi ne olursa olsun, cezalarını kapalı ceza infaz kurumunda çekmeye başlarlar.

Bu istisnai hükümlülerin önemli bir kısmının cezasını yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda çekeceklerini dikkatten uzak tutmamak gerekir (Bkz, İnfaz K, m. 9, f. 2).

Kapalı ceza infaz kurumunda cezasının infazına başlanan hükümler, cezalarının belli bir miktarını bu kurumda çektikten sonra, **açık ceza infaz kurumuna nakledilirler**^{260 261}.

²⁶⁰ Bu hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna nakline ilişkin koşullar, İnfaz Kanununun 14. maddesine istinaden Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan “**Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği**”nde (RG: 2 Eylül 2012 / 28399) belirlenmiştir (m. 6). Söz konusu Yönetmelikte yapılan son değişiklik, **11 Nisan 2019** tarihli ve 30742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin son haline göre,

“**MADDE 6 – (1) Hükümlülerden;**

a) Toplam cezaları on yıldan az olanlar **bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise onda birini** kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olan ve **koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar,**

b) Müebbet hapis cezasına mahkûm olup, **koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalanlar,**

c) Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının **üçte birini** bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve **koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar,**

açık kurumlara ayrılabilir.

(2) Açık kurumlara ayrılabilmek için, ayrıca;

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142, 148, 149, 188 ve 190’ıncı maddeleri ile 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404, 491/3-4, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinden mahkûm olanların **koşullu salıverilme tarihine beş yıldan az süre kalması,**

b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 ve 103’üncü maddeleri ile eşe karşı işlenen 82/1-d, 86/3-a ve 96/2-b maddeleri ve 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 414, 416/1, 418/1 maddeleri ile eşe karşı işlenen 449/1, 456 ve 457/1 maddelerinden mahkûm olanların **koşullu salıverilme tarihine üç yıldan az süre kalması,**

...

ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin **koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması,**

şartı aranır.

(3) Birden fazla cezanın toplanarak infazı hâlinde, açık kuruma ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur.

(4) Açık kuruma ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık deneme süresinin tamamlanması beklenmeden açık kuruma ayrılma kararı alınabilir.”

²⁶¹ Kapalı ceza infaz kurumunda cezasını çekmekte olan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna nakline ilişkin değerlendirme usulüne ve alınacak kararlara ilişkin olarak bkz. İnfaz K. m. 14, f. 3, 4; m. 89.

Ancak, haklarında iyi hal kararı verilse bile, İnfaz Kanunu'nun 44. maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar açık ceza infaz kurumlarına ayrılamazlar. (Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, m. 8, f. 1, bent c).

Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, 6. maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalanlar açık ceza infaz kurumlarına ayrılamazlar. (Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, m. 8, f. 1, bent d).

“Ayrıca;

- a) **Koşullu salıverilme kararı geri alınanların, geri alınan cezalarının tamamı,**
- b) **Denetimli serbestlik tedbirinin ihlali sonucunda, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin tamamı,**
- c) **Çocuk eğitimevleri hariç, kapalı kurumlardan **fırar edenler** ile açık kurumlardan ikinci kez fırar etmiş olanların, fırar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı,**
- ç) **2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince verilen hapsen tazyik veya tazyik hapisleri dışında, diğer kanunlarda düzenlenen tazyik, **disiplin** veya **zorlama hapislerinin tamamı,****

kapalı kurumlarda infaz edilir.” (Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, m. 8, f. 2).

14.7.2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanunla (m. 15) İnfaz Kanununa eklenen “**Geçici madde 10**” düzenlemesi kapsamında, “31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası on yıldan az ise bir ayını, on yıl ve daha fazla ise üç ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına üç yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların olduğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir. Bu hükümlüler ile 31/7/2023 tarihinde geçici 9’uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamında açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri hâlinde en az üç ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından üç yıl erken yararlandırılır.” (f. 6)

Ancak “Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar” dolayısıyla mahkûm olanlar, bu hükümlerden yararlanamayacaktır (İnfaz K, geçici m. 10, f. 6)²⁶².

²⁶² Kapalı ceza infaz kurumunda cezasını çekmekte olan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna nakline ilişkin koşullar işlenen suça ve mahkûm olunan ceza miktarına göre farklılık arz edebilir.

İnfaz Kanununda, cezasını yüksek güvenlikli veya diğer kapalı ceza infaz kurumlarında çekmekte olan hükümlülerden cezalarının infazı sürecinde iyi halli olmalarına rağmen açığa ayırlamayacak olanlara ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda “**Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği**”nde düzenleme yapılmıştır²⁶³. Kişi hak ve hürriyetlerine kısıtlama getiren özellik taşıması itibarıyla bu düzenlemenin **Anayasaya aykırı** olduğunu belirtmek gerekir.

E. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler

“**Açık ceza infaz kurumları**, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.” (İnfaz K, m. 14, f. 1)^{264, 265}.

İnfaz hukuku alanındaki düzenlemelerle ilgili zaman bakımından derhal uygulama kuralı gereğince, bu koşullara ilişkin kanuni düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren cezasını çekmekte olan bütün hükümlüler bakımından uygulanır. Bu koşulların uygulanmasına mahkum olunan cezanın çekildiği tarih itibarıyla sınırlama getirilmesi, Anayasa (m. 10) ile güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. Bu itibarla, İnfaz Kanununa 14.7.2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanunla eklenen geçici m. 10, f. 6 hükmü Anayasaya aykırıdır. Ancak, Anayasa Mahkemesi, buna rağmen söz konusu hükmü iptal etmemiştir (7.3.2024, E. 2023/148, K. 2024/70 [RG: 19 Nisan 2024-32522]). Bu kararın oy çokluğu ile alınmış olduğunu belirtmek gerekir.

²⁶³ Cezalarını kapalı infaz kurumunda çekmeye başlayan ve fakat, **açık ceza infaz kurumuna nakledilemeyen hükümlülere ilişkin koşullar**, söz konusu Yönetmeliğin 8. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre:

“**Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar, açık kurumlara ayırlamaz**” (f. 1, bent a).

Keza, haklarında **ikinci defa tekerrür** hükümleri uygulananlar, açık ceza infaz kurumlarına ayırlamazlar (f. 1, bent b).

“Ayrıca;

a) **Koşullu salıverilme kararı geri alınanların, geri alınan cezalarının tamamı,**

b) **Denetimli serbestlik tedbirinin ihlali sonucunda, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin tamamı,**

c) **Çocuk eğitimevleri hariç, kapalı kurumlardan firar edenler ile açık kurumlardan ikinci kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı,**

ç) **2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince verilen hapsen tazyik veya tazyik hapisleri dışında, diğer kanunlarda düzenlenen tazyik, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı,**

kapalı kurumlarda infaz edilir.” (m. 8, f. 2).

Yine, başka bir suçtan dolayı haklarında tutuklama kararı verilmiş olan hükümlüler, açık kurumlara ayırlamazlar (m. 8, f. 3, bent a).

Ancak, mevzuatımız İnfaz Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan disipline aykırı fiilleri işlemek dolayısıyla hakkında hücreye koyma disiplin yaptırımı uygulanan hükümlülerin de mümkün olduğunca açık ceza infaz kurumuna ayrılmasını kolaylaştırıcı hükümler içermektedir (söz konusu Yönetmelik, m. 8, f. 1, bent c).

²⁶⁴ Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin bir beceri kazanmalarını sağlamak ve üretimde bulunmak amacına yönelik bir fonksiyon icra etmektedir. Hükümlüler, açık ceza infaz kurumla-

“Aşağıdaki hâllerde hükümlüler hakkında verilen cezalar **doğrudan** açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir:

a) Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, **kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar**.

b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar.

c) Adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler.

d) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar.” (İnfaz K, m. 14, f. 2)²⁶⁶.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kapalı ceza infaz kurumunda cezasının infazına başlanan hükümler, cezalarının belli bir miktarını bu kurumda çektikten sonra, açık ceza infaz kurumuna nakledilmektedirler²⁶⁷.

rındaki iş atölyelerinde çalıştırılarak, meslek ve sanat öğrenmeleri sağlanmakta ve üretime katkıda bulunmaktadır.

²⁶⁵ Açık ceza infaz kurumları, “**Kadın açık ceza infaz kurumları**” ve “**Gençlik açık ceza infaz kurumları**” (İnfaz K, m. 14, f. 1; İnfaz Tüzüğü, m. 16, f. 1) şeklinde kurulabilirler.

²⁶⁶ Ayrıca bkz. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, m. 5.

²⁶⁷ Açık ceza infaz kurumuna alınmış olan veya cezasını açık ceza infaz kurumunda çekmekte olan hükümlüler, belirli hallerde **kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilebilmektedirler**:

“Doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden;

a) Firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler idare ve gözlem kurulu kararıyla,

b) Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulu kararıyla,

c) Açık ceza infaz kurumu şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar idare ve gözlem kurulunun kararı ve infaz hâkiminin onayıyla,

kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilirler.” (İnfaz K, m. 14, f. 5).

Keza cezası açık kurumlarda infaz edilmekte olan hükümlülerden;

a) haklarında başka bir suçtan dolayı tutuklama kararı verilenler,

b) firar edenler,

c) kınamadan başka bir disiplin cezası alıp disiplin cezası kesinleşenler,

ç) cezasını çekmek üzere doğrudan açık infaz kurumlarına gönderilenler hariç olmak üzere; yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları tespit edilenler,

d) iş temin edildiği halde çalışmayanlar veya iş düzenine uyum sağlayamayanlar,

kapalı kurumlara iade edilir (Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, m. 12, f. 1)

Söz konusu Yönetmelikte kapalı infaz kurumlarına iadeye ilişkin ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir: m. 12, f. 2; m. 13.

F. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden ve sıkı güvenlik rejimine göre çektilen hapis cezasıdır (TCK, m. 47, f. 1)²⁶⁸.

²⁶⁸ Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazında;

- a) Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.
- b) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.
- c) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hale göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabilir, kendisi ile aynı üniteye kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.
- d) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.
- e) Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hallerde ve on beş günde bir kez olmak üzere eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisine, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir.
- f) Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde on beş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
- g) Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılmaz ve kendisine izin verilmez.
- h) Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.
- i) Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbi tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında uygulanır. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu tedbirler, tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koşullarında uygulanır (İnfaz K, m. 25, f. 1).

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, **yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında** infaz edilir (İnfaz K, m. 9, f. 2). Bu hükümlüler, cezalarının infazı sürecinde açık ceza infaz kurumlarına ayrılmazlar (Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, m. 8, f. 1, bent a).

Ayrıca belirtmek gerekir ki,

suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek suçundan,

veya,

suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza Kanununda yer alan;

- insanlığa karşı suçlardan (TCK, m. 77, m. 78),
- kasten öldürme suçlarından (TCK, m. 81, m. 82),
- uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (TCK, m. 188),
- devletin güvenliğine karşı suçlardan (TCK, m. 302, m. 303, m. 304, m. 307, m. 308), veya,
- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (TCK m. 309, m. 310, m. 311, m. 312, m. 313, m. 314, m. 315)

mahkûm olanların cezaları süresine bakılmaksızın, **yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında** infaz edilir (İnfaz K, m. 9, f. 2).

Ancak bu hükümlüler, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği, m. 6 ve 10 hükümlerine göre, cezalarının belirli bir miktarını yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda çektikten sonra, açık ceza infaz kurumuna gönderilir ve cezasını bu infaz kurumunda çekmeye devam ederler.

G. Müebbet Hapis ve Süreli Hapis Cezasının İnfazı

“*Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.*” (TCK, m. 48, f. 1). “*Bu ceza süreli hapis cezasına uygulanan infaz rejimine göre infaz edilir.*” (İnfaz Yönetmeliği, m. 36, f. 1, ikinci cümle).

Müebbet hapis cezasının infazına, **kapalı ceza infaz kurumunda** başlanır. Yukarıda ayrıntısıyla anlatıldığı gibi, *Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği*, m. 6 ve 10 hükümlerine göre, bu cezanın belirli bir miktarı, kapalı ceza infaz kurumunda çekildikten sonra, hükümlü açık ceza infaz kurumuna gönderilir ve cezasını bu infaz kurumunda çekmeye devam eder.

Keza, yukarıda açıklandığı üzere, belirli bir miktarın üzerinde süreli hapis cezasına mahkum olanlar, cezalarını **kapalı ceza infaz kurumlarında** çekmeye başlarlar. Bu hükümlüler de “**Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği**”, m. 6 ve 10 hükümlerine göre, cezalarının belirli bir miktarını kapalı ceza infaz kurumunda çektikten sonra açık ceza infaz kurumuna gönderilirler ve cezalarını bu infaz kurumunda çekmeye devam ederler.

Ancak yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, “**Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği**”, m. 8 hükümlerine göre, cezasını kapalı ceza infaz kurumunda çekmeye başlayan belirli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılamazlar.

Yukarıda açıklandığı üzere, süreli hapis cezalarının belirli bir miktarı aşmayanlarının infazına, doğrudan açık ceza infaz kurumunda başlanabilir.

H. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi

Yukarıda da belirtildiği gibi, infaz hukukunda **derhal infaz** kuralı geçerlidir. Kesinleşen hapis cezası **geciktirilmeksizin** infaz edilir. Bu itibarla, **hükümlünün askerlik görevi, mahkum olduğu hapis cezasının infazı bakımından bir erteleme sebebi oluşturmaz**²⁶⁹. İnfaz kurumuna kabul edilen hükümlünün askerlik yükümlülüğünü yerine getiren bir kişi olduğunun anlaşılması halinde,

²⁶⁹ Ancak, hükümlünün mahkum olduğu kısa süreli hapis cezası, “tedbir” olarak,

a) “*En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye*” (TCK, m. 50, f. 1, bent c),

b) “*Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya*” (TCK, m. 50, f. 1, bent e),

c) “*Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya*” (TCK, m. 50, f. 1, bent f),

çevrilmiş ise, bu tedbirlerin infazı, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonra bırakılır (İnfaz K, m. 118, f. 1).

durum kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine bildirilir. Askerlik yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş olan hükümlülerin infaz kurumunda bulunduğu ve bilahare koşullu salıverildikleri, kayıtlı bulundukları askerlik şubesine bildirilir (İnfaz K, m. 22, f. 3).

Ancak İnfaz Kanununda bazı koşulların varlığı halinde, **hapis cezasının infazının geriye bırakılabilmesine** imkan tanıyan hükümlere yer verilmiştir. Bu bağlamda önemle belirtelim ki, TCK'nın 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi kurumu ile İnfaz Kanununun 16, 16/A ve 17. maddelerinde düzenlenen hapis cezasının infazının ertelenmesini birbirine karıştırmamak gerekir.

Hapis cezasının ertelenmesine hükmü veren mahkeme karar verir. Hapis cezası ertelenen kişi koşullarına uyduğu takdirde cezasını hiç infaz kurumuna girmeden toplumsal ortamda çekmektedir. Buna karşılık hapis cezasının infazının ertelenmesinde ise, kişi cezasını infaz kurumunda çekecektir. Ancak bu durumda, infaz hukukunun ilkelerinden biri olan derhal infazdan belirli bir süre ve belirli koşullarla sarfinazar edilebilmektedir. Bu konuda Cumhuriyet başsavcılığınca karar verilmektedir (İnfaz K, m. 16, f. 3).

1) Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi

Hastalanan hükümlü, kural olarak, cezasını “*resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde*” tedavi görerek çeker (İnfaz K, m. 16, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m.42, f.2). Bu nedenle, hükümlünün hasta olması, kural olarak, mahkum olduğu hapis cezasının infazı bakımından bir engel oluşturmaz.

Ancak, hastalığın tedavisinin “*resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde*” yapılarak infaza devam edilmesi “*mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa ... cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.*” (İnfaz K, m. 16, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m.42, f.2)²⁷⁰.

Keza, “*maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı ... iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.*” (İnfaz K, m. 16, f. 6; İnfaz Yönetmeliği, m.42, f.6).

Bu durumlarda infazın ertelenmesine, ancak “*Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kuruluşlarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapı-*

²⁷⁰ Akıl hastalığına tutulan hükümlünün hapis cezasının infazı geri bırakılır. Hükümlü iyileşinceye kadar TCK, m. 57 hükmünde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır (İnfaz K, m. 16, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m.42, f.1)

lacağı Cumhuriyet başsavcılığınca” karar verilir (İnfaz K, m. 16, f. 3; İnfaz Yönetmeliği, m. 42, f. 3)^{271,272}.

Ancak belirtmek gerekir ki, aşağıda ayrıntısıyla açıklanacağı üzere, hapis cezasının infazına infaz kurumunda başlandıktan sonra, ancak belirli koşulların ortaya çıkması halinde, **infaza ara verilebilmektedir**; yani bu durumlarda, **infaz durdurulabilmektedir** (İnfaz K, m. 17, f. 4).

Gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan hükümlü kadının mahkum olduğu hapis cezasının **infazı da geri bırakılır**. Bu durumda cezanın infazı, gebelik süresince ve doğumdan itibaren bir yıl altı aylık sürenin dolmasına kadar ertelenecektir²⁷³ (İnfaz K, m. 16, f. 4; İnfaz Yönetmeliği, m.42, f.4). Ancak bu arada çocuk ölmüş ise, doğumdan itibaren iki ayın geçmesiyle infaza başlanır (İnfaz K, m. 16, f. 4; İnfaz Yönetmeliği, m.42, f.4).

İnfazın geri bırakılmasına (ertelenmesine) ilişkin bu hükümler, adli para cezasının ödemek suretiyle infaz edilememesi dolayısıyla çevrilen hapis bakımından da uygulanabilir (İnfaz K, m. 106, f. 9).

2) Çocuğunun Hastalığı Nedeniyle Kadın Hükümlünün Cezasının İnfazının Ertelenmesi

7445 sayılı Kanunla İnfaz Kanunu’na eklenen 16/A maddesi kapsamında; engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan çocuğu bulunan kadın hükümlünün mahkûm olduğu hapis cezasının infazının ertelenmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu kapsamda; İnfazına başlanmış olsa bile, toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan on sekiz yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi hâlinde, cezasının infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilir (İnfaz Kanunu, m. 16/A).

²⁷¹ Bu durumda cezanın infazı, raporda belirtilen süre kadar ertelenebilecektir. Raporda süre belirtilmemişse, infaz, her defasında yeniden rapor alınması kaydıyla, bir yıllık dönemler halinde ertelenebilecektir (İnfaz Kanunu, m. 16, f. 3; İnfaz Yönetmeliği, m. 42, f. 3).

²⁷² Aynı şekilde, maruz kaldığı “**ağır bir hastalık**” nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği, İnfaz Kanunu, m. 16, f. 3 hükümlerine göre tespit edilen şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecektir (CMK, m. 109, f. 4). Ceza Muhakemesi Kanununun 109. maddesindeki bu düzenleme, 14.4.2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunla yapılmıştır. Şüpheli veya sanığın tutuklanmasının hakim in takdirinde olması karşısında, doğru olmadığı değerlendirilen bu düzenlemeyle tutuklu olan şüpheli veya sanığın ağır hastalık veya engellilik sebebiyle tahliyesine karar verilmesi, esasında zorlaştırılmıştır.

²⁷³ “Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının dördüncü fıkra da öngörülen kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur.” (İnfaz Yönetmeliği, m.42, f.5)

Erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabilir. Dolayısıyla bu kapsamda infazın ertelenmesi en fazla üç yıl süreyle mümkündür. Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemez.

Çocuğun engellilik nedeniyle bakıma muhtaç olma veya ağır hastalık hâli, 16'ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenir. Buna göre söz konusu tespit Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılır

İnfaz Kanunu m. 16/A kapsamında hapis cezasının infazı ertelenen hükümlü erteleme süresince Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenen yükümlülüklerle tabi tutulur. Bu kapsamda hükümlü;

- a) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek,
- b) Belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak,
- c) Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak belirlenen güvence miktarını yatırmak,

yükümlülüklerinden en az birine tâbi tutulur. Hükümlü hakkında ayrıca Cumhuriyet savcısı tarafından yurt dışına çıkamama yükümlülüğü konulur.

Erteleme süresi içinde; hükümlünün erteleme amacına veya yükümlülüklerle aykırı davrandığının denetimli serbestlik müdürlüğü veya kolluk birimlerince tespit edilmesi, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması veya çocuğun iyileşmesi hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhâl infaz olunur.

3) Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün Talebiyle Ertelenmesi

İnfaz için çağrıldığında gelen hükümlünün hapis cezasının infazı belirli koşulların varlığı halinde ve belirli süre ile **ertelenebilir** (İnfaz K, m. 17, f. 1). Bu itibarla, yakalama suretiyle ele geçirilen hükümlü ile ilgili olarak söz konusu erteleme hükümleri uygulanamayacaktır.

Bu durumda infazın ertelenmesine ancak **talep üzerine** karar verilebilir ve karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir^{274, 275}.

Bu çerçevede, kasten işlenen suçlarda ancak üç yıl veya daha az süreli hapis cezası, taksirli suçlarda ise, ancak beş yıl veya daha az süreli hapis

²⁷⁴ “Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.” (İnfaz K, m. 17, f. 5; İnfaz Yönetmeliği, m.43, f.5).

²⁷⁵ “Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.” (İnfaz K, m. 17, f. 3; İnfaz Yönetmeliği, m.43, f.3).

cezasının infazı ertelenebilir (İnfaz K, m. 17, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m.43, f.1)²⁷⁶.

“Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.” (İnfaz K, m. 17, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m.43, f.2).

Dikkat edilmelidir ki, hapis cezasının infazının talep üzerine ertelenebilmesi için, Kanunda herhangi bir **sebepl sınırlaması söz konusu değildir**.

Buna karşılık, kasten işlenen suçlarda üç yıl veya daha az süreli, taksirli suçlarda beş yıl veya daha az süreli hapis cezasının infazına başlanmış ise, **ancak belirli sebeplerin varlığı halinde, infaz durdurulabilmektedir**:

“Hükümlünün,

- yükseköğrenimini bitirebilmesi,

- ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi,

- eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları,

veya,

- hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi,

gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde,

Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz.” (İnfaz K, m. 17, f. 4; İnfaz Yönetmeliği, m. 43, f. 4).

Bu itibarla, infazın ertelenmesi bakımından sebep aranmamış iken, başlamış olan infazın durdurulabilmesi için, belirli sebeplerin ortaya çıkması gerekmektedir. Başlamış olan infaza ara verilmesi, yani infazın durdurulması için sebepler tadadı değildir. Maddede sayılan sebepler örnek kabilinden zikredilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken, ancak **“zorunlu ve ivedi hâllerde”** hapis cezasının infazının durdurulabilmesine imkan tanınmış olmasıdır. Bunu takdir etme yetkisi, Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilmiştir. Durdurma her defasında

²⁷⁶ Ancak, mahkum oldukları hapis cezasının süresi ne olursa olsun;

“a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar,

b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,

c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar,”

hakkında istem üzerine hapis cezasının infazının ertelenmesi yoluna gidilememektedir (İnfaz K, m. 17, f. 6; İnfaz Yönetmeliği, m.43, f.6).

azami altı aylık süreyle ve ancak iki defa mümkündür. Kanaatimizce infazın durdurulmasına ilişkin sayı sınırlaması, aynı sebep bakımından söz konusudur.

Dikkat edilmelidir ki, hapis cezasının infazına ara verimesi (infazının durdurulması) halinde, hükümlünün infaz kurumu dışında geçirdiği süre infazdan sayılmayacaktır.

4) Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması

İştirak halinde işlenen suçlardan dolayı ilk derece mahkemesince verilen mahkumiyet hükmünün istinaf edilmesi halinde çeşitli ihtimaller karşımıza çıkabilir.

Birinci ihtimal olarak, ilk derece mahkemesi tarafından verilen ve istinaf başvurusu reddedilen mahkumiyet hükmünde, suç ortaklarından biri örneğin yedi yıl, diğeri ise on yıl hapis cezasına mahkum edilir.

İkinci ihtimal olarak, ilk derece mahkemesi tarafından verilen beraat veya mahkumiyet hükmü kaldırılarak, istinaf mahkemesi tarafından verilen yeni mahkumiyet hükmünde, suç ortaklarından biri örneğin yedi yıl, diğeri ise on yıl hapis cezasına mahkum edilir.

Bu iki ihtimalde, istinaf mahkemesi tarafından verilen hükümlere karşı temyiz kanun yoluna başvurulabilir (CMK, m. 286).

Buna karşılık;

- birinci ihtimal olarak, ilk derece mahkemesi tarafından verilen ve istinaf başvurusu reddedilen mahkumiyet hükmünde, suç ortaklarından birinin örneğin beş yıl, diğeri ise sekiz yıl hapis cezasına mahkum edilmesi

veya

- ikinci ihtimal olarak, ilk derece mahkemesi tarafından verilen beraat veya mahkumiyet hükmü kaldırılarak, istinaf mahkemesi tarafından verilen yeni mahkumiyet hükmünde, suç ortaklarından birinin örneğin beş yıl, diğeri ise sekiz yıl hapis cezasına mahkum edilmesi

hallerinde, sekiz yıl hapis cezasına mahkum edilen suç ortağı ile ilgili olarak verilen mahkumiyet hükümlerinin temyiz edilebileceği hususunda kuşku bulunmamaktadır.

Bu bağlamda sorun, beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum edilen suç ortağı ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır.

CMK'nın mevcut düzenlemelerine göre,

- a) beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkumiyet hükümlerine ilişkin istinaf başvurusunun reddi kararı,

ve

- b) istinaf mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesinin hükmü kaldırılarak verilen yeni hükümde hakkında beş yıl veya daha az hapis cezasına hükmedilen suç ortağı ile ilgili mahkumiyet hükmü,

temyiz edilemez.

Mevzuatın bu düzenlemesi itibarıyla şöyle bir durumla karşılaşılabilir:

Suç ortaklarından biri mesela sekiz yıl hapis cezasına mahkum edildiği için, bu karar temyiz edilir. Temyiz edildiği için bu suç ortağı ile ilgili mahkumiyet hükmü henüz kesinleşmemiş olacaktır. Buna karşılık, mesela beş yıl hapis cezasına mahkum olan suç ortağı ile ilgili mahkumiyet hükmü ise, temyiz yolu kapalı olduğu için kesinleşecektir. Bu bağlamda sorun, kesinleşen mahkumiyet hükmünün infazına başlanmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Temyiz edilen mahkumiyet hükmünün, Yargıtay tarafından bozulması mümkündür. CMK, m. 306 hükmü karşısında, bu bozma kararının, diğer suç ortağı ile ilgili olarak verilen ve temyiz yolu kapalı olduğu için kesinleşen mahkumiyet hükmü bakımından da bozma etkisi doğuracağını evleviyetle kabul etmek gerekir.

Suç ortaklarından biriyle ilgili olarak verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasına yönelik karardan, temyiz kanun yoluna başvuramayan ve bu nedenle mahkumiyet hükmü kesinleşen diğer suç ortağı yararlanabilmelidir.

Bu nedenle, bir suç ortağı ile ilgili olarak verilen mahkumiyet hükmünün temyiz incelemesi sonucunda bozulması halinde, diğer bir suç ortağı ile ilgili olarak verilen ve temyiz kanun yolu kapalı olduğu için veya temyiz kanun yoluna başvurmadağı için kesinleşen mahkumiyet hükmü kaldırılarak, bu suç ortağının da yeniden yargılanması ve hakkında yeni bir hüküm tesis edilmesi gerekir.

Bu ihtimalin söz konusu olduğu durumlarda, **istinaf** incelemesini yapan mahkemenin, temyiz kanun yolu kapalı olduğu için kesinleşen mahkumiyet hükmüyle ilgili olarak, **infazın ertelenmesine** karar vermesi, adaletin bir gereğidir. Mevzuatımızda doğrudan doğruya bu duruma özgü bir kanun hükmü bulunmakla birlikte, 5275 s. İnfaz Kanunu, m. 98 ve 5252 s. TCK Yürürlük Kanunu, m. 10 hükümleri kıyasen uygulanarak, bu yönde karar verilmesi gerekmektedir.

Ancak, bu konuda uygulamamızda oluşan tereddüdü gidermek amacıyla İnfaz Kanununa 17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanunla (m. 32) yeni bir madde eklenmiştir:

“Mahkemece infazın ertelenmesi veya durdurulması

MADDE 17/A- (1) Birlikte işlenmiş olup da 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 306’ncı maddesinin uygulanma olanağının bulunduğu hâllerde, **hükmü veren ilk derece mahkemesinden infazın ertelenmesine veya durdurulmasına**

ilişkin karar verilmesi istenebilir. Karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmesi istenebilir. Karar, duruşma açılmaksızın verilir ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Erteleme veya durdurma talebinin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.” (Ayrıca bkz. İnfaz Yönetmeliği, m. 44, f. 1)

Dikkat edilmelidir ki bu hükümler, sadece hapis cezası bakımından değil, adli para cezası bakımındanda dikkate alınmak gerekir.

I. Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi ve Haberleşmesi

Anayasal bir hak olan haberleşme hakkı (AY, m. 22), infaz kurumunda cezasını çekmekte olan hükümlünün de yararlanabileceği bir haktır. Bu hakkın mutlak surette kısıtlanması mümkün değildir. İnfaz kurumunda cezasını çekmekte olan hükümlüyü dış dünyadan mutlak surette tecrit eden bir uygulama; insan onuru ile bağdaşmaz. Ancak infaz kurumunda cezasını çekmekte olan hükümlüler bakımından bu hakka **kanunla** bazı sınırlamalar getirilmiştir. Belirli sınırlamalara rağmen, hükümlünün bu hakkı kullanması, onun dış dünya ile bağ kurmasını sağlayacak, bu durum cezanın temel amaçlarından olan hükümlüyü tekrar topluma kazandırmaya hizmet edecektir.

1) Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi

Hapis cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlü belirli akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu kişilerle herhangi bir izne tabi olmadan **yüz yüze görüşme** hakkına sahiptir (İnfaz K, m. 83, f. 1). Bu kişiler, hükümlünün,

- a) eşi,
 - b) birinci, ikinci ve üçüncü derece kan ve kayın hısımları,
 - c) vasisi veya kayyımı,
- olabilir.
- Hükümlü, bu kişilerle,
- a) haftada bir kez,
 - b) çalışma (mesai) saatleri içinde²⁷⁷,
 - c) yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla olmamak üzere²⁷⁸,
- görüşme hakkına** sahiptir²⁷⁹.

²⁷⁷ Bu görüşme tatil günlerinde örneğin dinî bayram günlerinde de olabilir. Bu görüşme, kapalı veya açık biçimde olabilir.

²⁷⁸ Çocuk hükümlüler bakımından bu süre asgari bir saat, azami üç saat olmak üzere belirlenir.

²⁷⁹ Anayasa Mahkemesinin 3.7.2019 tarihli ve 2016/57050 Başvuru numaralı bireysel başvuru kararında (RG: 31 Temmuz 2019/30848) yol göstericilik özelliği olan şu açıklamalara yer verilmiştir:

“51. Anayasa'nın 19. maddesi gereğince hükümlü ve tutukluların özel ve aile hayatının sınırlandırılması hukuka uygun olarak ceza infaz kurumunda tutulmanın kaçınılmaz ve doğal bir sonucudur. Öte yandan hükümlü ve tutukluların özel ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı, ceza infaz kurumu idaresinin hükümlü ve tutukluların ailesi ve yakınlarıyla temasını devam ettirecek önlemleri almasını zorunlu kılmaktadır (Mehmet Zahit Şahin, B. No: 2013/4708, 20/4/2016, § 36). Bununla beraber bu yükümlülük yerine getirilirken ceza infaz kurumunda tutulmanın doğal sonuçlarının gözetilmesi gerekmektedir.

52. Devletin hükümlü ve tutukluların ailesi ve yakınlarıyla iletişimini devam ettirecek önlemleri alması pozitif yükümlülüklerinin bir gereği olsa da -belirtildiği üzere- hukuka uygun bir tutulmadan kaynaklanan kaçınılmaz sonuçlar nedeniyle aile hayatı kapsamındaki temasın sınırlandırılması doğaldır. Kamu düzeninin ve kurum güvenliğinin sağlanması yönündeki meşru amaç doğrultusunda ve makul bir gerekliliğin olması durumunda gerekçeleri ilgili ve yeterli şekilde açıklanarak belirli bir süre boyunca söz konusu pozitif yükümlülüğün karşılanmaması da olağan kabul edilebilir. Ancak aile hayatına saygı hakkının gereklerinin mümkün olan ilk fırsatta yerine getirilmesi ve mahpusların ailesiyle olan temasının hızlı şekilde yeniden sağlanması bir gerekliliktir.

53. Bu bağlamda tutuklu ya da hükümlünün aile hayatını sürdürmesini sağlamaya yeterli olacak şekilde yakın derecedeki aile bireyleriyle asgari düzeyde bir iletişim ve temas kurması her durumda sağlanmalıdır. Böylesi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve tedbirler alınması, aile hayatına saygı hakkı kapsamında devletten beklenen asgari bir gerekliliktir. Birtakım teknik ya da fiziki olanakların bulunmaması, tutuklu ya da hükümlünün ailesiyle asgari şekilde iletişim ve temas kuramamasına gerekçe olarak gösterilemez. Zira mahpusun ailesiyle iletişim kurması her durumda mutlaka yüz yüze görüştürülmesi anlamına gelmemektedir.

54. Örneğin farklı yerleşkelerde veya farklı şehirlerde bulunan ceza infaz kurumlarında barındırılan mahpusların birbirleriyle yüz yüze görüştürülmeleri beklenemez. Ancak yakın aile bağı olan bu durumdaki mahpusların birbirleriyle uygun vasıtalar aracılığıyla görüştürülmelerinin sağlanması gerekir. Öte yandan aynı yerleşke içindeki farklı ceza infaz kurumlarında tutulan yakın aile bireylerinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak mümkün olduğunca belirli dönemlerde yüz yüze görüştürülmeleri aile hayatına saygı hakkının gerekli kıldığı yükümlülüğün bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Nitekim belirtilen son hâlde aile bireylerinin yüz yüze görüştürülmeleri kamusal makamlara katlanılması mümkün olmayan bir külfet yüklememektedir.

55. Tüm durumlarda önemli olan husus yakın aile bireylerinin birbirlerinden haberdar olabilmeleri, aile hayatlarına ilişkin konuları konuşabilme imkânından yoksun bırakılmamalarıdır. Elbette aile bireylerinin birbirleriyle temas etmesine ve aile ilişkilerinin sürdürülmesini sağlamaya elverişli kabul edilen uygun vasıtaların, suç işlenmesinin önlenmesi ya da yasa dışı haberleşmenin önüne geçilmesi amacıyla ilgili idare tarafından denetlenmesi ve gerektiğinde izlenmesi de mümkündür. Bu şekilde denetleme ve izleme yetkileri olmasına rağmen haklı bir gerekçe olmaksızın kamusal makamlar tarafından tutuklu ya da hükümlünün ailesiyle asgari bir iletişim kurmasına imkân sağlanmaması aile hayatına saygı hakkının ihlaline neden olabilir.

56. Vurgulandığı üzere tutuklu ya da hükümlünün ailesiyle asgari bir iletişim kurmasının sağlanması şeklindeki pozitif yükümlülük özellikle aile bireylerinin her ikisinin de mahpus olduğu ve aynı yerleşke içinde tutulmadıkları durumlarda bu kişilerin mutlaka yüz yüze, yakın şekilde görüştürülmesini gerekli kılmaz. Belirtilen asgari iletişim, söz konusu aile bireylerinin belirli ve makul aralıkta başta telefon olmak üzere uygun vasıtalarla birbirleriyle görüştürülmeleri yoluyla da sağlanabilir. Sadece mektup yoluyla haberleşme ise -istisnai durumlar hariç olmak üzere- aile bireylerinin birbirleriyle olan ve aile hayatına saygı hakkı kapsamında korunan temasını sürdürülmesini sağlamaya uygun bir vasıta olarak kabul edilmemelidir. Zira mektup yoluyla haberleşme, tek başına aile ilişkilerinin sürdürülmesine olanak sağlayacak kapsamı ve hızı içeren bir vasıta olarak nitelendirilmeye elverişli değildir.”

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaretçileriyle görüşmesi, “kapalı ve açık olmak üzere” iki şekilde yapılabilir (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik, m. 5, bent c)²⁸⁰.

Hükümlünün ayrıca isimlerini ve adreslerini önceden infaz kurumuna bildirdiği en fazla üç kişi de bu şekilde yani ayrıca bir **izne tabi olmadan** hükümlüyü ziyaret hakkına sahiptir (İnfaz K, m. 83, f. 1)²⁸¹.

Bunların dışındaki kişiler, ancak **Cumhuriyet başsavcılığının yazılı iznine** dayalı olarak hükümlüyle görüşme imkanına sahip olabilirler (İnfaz K, m. 83, f.

²⁸⁰ “**Kapalı görüş**, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlenildiği, **konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği** ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşmelerdir.” (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik, m. 7).

“**Açık görüş**” ise, “hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkân verecek şekilde, **konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği**, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.” (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik, m. 13).

²⁸¹ Anayasa Mahkemesinin **18.7.2019** tarihli ve 2017/24068 Başvuru numaralı bireysel başvuru kararında (RG: 1 Ağustos 2019/30849) yol göstericilik özelliği olan şu açıklamalara yer verilmiştir:

“36. Somut olayda başvurunun ziyaretçi listesine iki kişinin eklenmesi yolundaki talebi *İnfaz Hâkimliği* tarafından Ziyaret Yönetmeliği’nde belirtilen altmış günlük süre içinde sunulmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca **temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlanabilir**. 5275 sayılı Kanun’da ziyaretçi isim listesinin bildirilmesi için herhangi bir hak düşürücü süre **öngörülmemiştir**. Ziyaret Yönetmeliği’nde ziyaretçi isimlerinin ziyaretle ilgili hususların tebliğ edildiği tarihten itibaren altmış gün içinde bildirilmesi öngörülmüş ancak bildirim için tanınan sürenin niteliği belirtilmemiştir. Ayrıca Ziyaret Yönetmeliği’nde sürenin geçmesinden sonra bildirimde bulunulmasına engel oluşturan bir kurala da rastlanmamaktadır. Bu durumda Ziyaret Yönetmeliği’nde belirtilen sürenin hak düşürücü değil düzenleyici süre olarak yorumlanabileceği anlaşılmaktadır. Olayda derece mahkemelerinin Ziyaret Yönetmeliği’ndeki altmış günlük sürenin hak düşürücü olduğu şeklindeki yorumları başvurunun ceza infaz kurumunda kaldığı süre boyunca ziyaretçi belirleme ve kabul etme hakkından yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu şekilde ziyaret hakkına getirilen kısıtlamanın hükümlü ve tutukluların dış dünyayla iletişim kurması ve sosyalleşmesi suretiyle iyileştirilmesi ilkelerine uygun düşüğü söylenemez.

37. Kaldı ki Ziyaret Yönetmeliği’nin 9. maddesinde, ceza infaz kurumu yönetimince gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı hakkında kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılacağı, sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmeyeceği ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi isteneceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla kamu makamlarının söz konusu yetkisi ışığında başvurunun ziyaretçi olarak görüşmek istediği kişiler hakkında kolluk vasıtasıyla araştırma yaptırma ve Kurumun güvenliği ve disiplini bakımından uygun görülmeyenlere ziyaret izni vermeme yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle kamu makamlarının bu şekildeki geniş takdir yetkisi gözetildiğinde başvurunun talebinin salt altmış günlük sürenin geçtiğinden bahisle reddedilmesinin özel hayata saygı hakkı ile kamu güvenliği amacı arasında adil denge sağlamaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvurunun ziyaretçi listesine iki kişinin eklenmesi talebinin reddedilmesi suretiyle özel hayata saygı hakkına yapılan müdahalenin ilgili ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığı, müdahalenin demokratik toplu düzeninde gerekli bir müdahale olmadığı sonucuna varılmıştır.”

2)²⁸². Bu görüşmenin ne zaman ve ne kadar süreyle yapılabileceği hususlarında İnfaz Kanununun 83. maddesinin birinci fıkrası hükümlerini göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu ziyaret sırasındaki konuşmaların gizliliğini sınırlandırma konusunda kanunda bir hüküm bulunmamaktaydı. İnfaz Kanununun 83. maddesine 17.6.2021 tarihli ve 7238 sayılı Kanunla eklenen fıkra, hükümlünün ziyareti sırasında yapılan konuşmaların gizliliğini sınırlandıran düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

“Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkûm olan veya tehlikeli hâlde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki kişilerle yapacakları görüşmeler, kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilir ve elektronik cihazlar da dâhil olmak üzere kaydedilebilir. Bu fıkra uyarınca tutulan kayıtlar, amacı dışında kullanılamaz ve kanunda açıkça belirtilen hâller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmayla konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinir. Silme işlemi Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir.” (f. 4)

Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan **“Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik”** hükümlerine göre,

*“Ziyaret esnasında görüşmelerin Türkçe yapılması esastır. Ancak, hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının Türkçe bilmediğinin beyan edilmesi halinde, Türkçe’den başka bir dilde konuşmanın yapılmasına izin verilir ve **konusma kayda alınır**. ...” (m. 41, f. 1).*

İnfaz Kanunu m. 83, f. 4’deki sınırlamalar dikkate alınmaksızın, Türkçeden başka bir dille yapılan görüşmelerin yönetmelik hükmüne istinaden kayda alınmasının **Anayasaya aykırı** olduğunu belirtmek gerekir.

Bunların dışında belirli amaçlar içinde infaz kurumları görülmek ve hükümlülerle görüşülmek istenebilir (İnfaz K, m. 85, f. 1). Örneğin bilimsel bir çalışma için veya basın mensupları ya da siyasi parti, dernek, vakıf, veya sendika mensupları tarafından infaz kurumlarının ziyareti ve hükümlülerle görüşme yapılması ancak **Adalet Bakanlığının izniyle** mümkündür. Bu iznin ilişkin olduğu hal, belirli bir hükümlüyle sınırlı olmaksızın yapılmak istenen görüşmelerdir. Bu ziyaret ve gö-

²⁸² Yabancı hükümlüler, vatandaşı oldukları devletin diplomatik temsilcileri ve konsolosluk yetkilileri tarafından da ziyaret edilebilir (İnfaz K, m. 84).

rüşme, bir kişi tarafından yapılabileceği gibi, **heyet** halinde de yapılabilir. Bu çerçevede infaz kurumlarını ziyaret edecek ve hükümlülerle görüşme yapacak kişiler vatandaş veya yabancı olabilir. Bu ziyaret ve görüşmeler, **kurum görevlilerinin gözetiminde** yapılır (İnfaz K, m. 85, f. 3). Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlülerle toplu görüşme yapılamaz (İnfaz K, m. 85, f. 4)²⁸³.

İnfaz Kanununda **yabancı hükümlülerin** ziyaretine ilişkin olarak da düzenleme yapılmıştır. Buna göre, yabancı hükümlülerin, vatandaşı olduğu devletin diplomatik temsilciliği veya konsolosluğunun ziyaret istemleri, mevzuatta belirlenen esas ve usullere uygun olarak geciktirilmeden yerine getirilir. Diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bulunmayan devletler vatandaşlığındaki hükümlüler ile mülteci veya vatansız olan hükümlülerin, yararlarını koruyan devletin diplomatik temsilciliği veya bu gibi kimseleri koruma görevini üstlenmiş ulusal veya uluslararası kuruluşlarla görüştürülmeleri de mümkündür (İnfaz K, m. 84)²⁸⁴.

Hapis cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlü **avukatla** da görüşme hakkına sahiptir^{285, 286}. Hükümlü, avukatla ancak **tatil günleri dışında** ve **çalışma** (mesai) **saatleri içinde** görüşebilir (İnfaz K, m. 59, f. 2). “*Hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekâletnamesi olmaksızın en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.*” (İnfaz K, m. 59, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 72, f. 2, bent a).

Avukatla hükümlü arasındaki görüşmede herhangi bir kişi hazır bulunmaz; ancak bu görüşme güvenlik nedeniyle **görülebilecek biçimde** yapılır (İnfaz K, m. 59, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m. 72, f. 2, bent c)²⁸⁷. Buna karşılık “**Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik**” hükümlerine göre ise, “*Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.*” (m. 20, f. 1). Keza, “*Tutuklu, vekaletname aranmaksızın müdafî ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne tabi olarak görüşür.*” (m. 19, f. 1, birinci cümle)²⁸⁸.

²⁸³ “**Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik**”te, tutuklu veya hükümlülerle heyet görüşmelerine ilişkin ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir (m. 26).

²⁸⁴ “**Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik**”te, yabancı tutuklu ve hükümlülerin ziyaretine ilişkin ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir (m. 27 vd.).

²⁸⁵ Hükümlünün avukatla görüşmesine ilişkin mevzuat hükümleri, noterler bakımından da geçerlidir.

²⁸⁶ Hükümlü, yabancı avukatla da belirli koşullarda görüşebilmektedir (İnfaz K, m. 59, f. 5).

²⁸⁷ “*Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü ile görüşme yapamazlar.*” (İnfaz K, m. 59, f. 3; İnfaz Yönetmeliği, m. 72, f. 2, bent b).

²⁸⁸ Söz konusu Yönetmelikte, tutuklu veya hükümlünün uzlaştırmacı, arabulucu ve noterle görüştürülmesine ilişkin ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir (m. 19 - 25).

Belirtmek gerekir ki, ceza infaz kurumlarına giren ve hükümlüyle görüşen avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar kurum yetkilileri tarafından incelenemez (İnfaz K, m. 86, f. 4; İnfaz Yönetmeliği, m. 72, f. 2, bent d). “*Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz.*” (İnfaz K, m. 59, f. 4)²⁸⁹.

²⁸⁹ Ancak belirtmek gerekir ki, İnfaz Kanunu, m. 59’da 3.10.2016 tarihli ve 676 sayılı KHK (m. 6) ve bu KHK’yi kanunlaştıran 1.2.2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanun (m. 6) ile değişiklikler yapılarak, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“(5) Türk Ceza Kanununun 220’nci maddesinde ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan **mahkûm olanların avukatları ile görüşmelerinde**, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne, **terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve tâlimat verildiğine** veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli **mesajlar iletildiğine** ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle; **görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir** veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.

(6) İnfaz hakimliği hükümlünün; kurallara uyumunu, toplum veya ceza infaz kurumu bakımından arz ettiği tehlikeyi ve rehabilitasyon çalışmalarındaki gelişimini değerlendirerek, kararda belirttiği süreyi üç aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa uzatabileceği gibi kısıtlanmasına veya sonlandırılmasına da karar verebilir.

(7) Beşinci fıkra kapsamına giren hükümlünün yaptığı görüşmenin, aynı fıkra da belirtilen amaca yönelik yapıldığının anlaşılması hâlinde, görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce taraflar bu hususta uyarılır.

(8) Hükümlü hakkında, yedinci fıkra uyarınca tutanak tutulması hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemiyle **hükümlünün avukatlarıyla görüşmesi** infaz hâkimince altı ay süreyle **yasaklanabilir**. Yasaklama kararı, hükümlüye ve yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. Cumhuriyet başsavcılığı baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesini baro başkanlığından isteyebilir. Bu fıkra hükmüne göre görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir.

(9) İnfaz hâkimisi tarafından bu madde uyarınca verilen kararlara karşı 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edilebilir.

(10) Bu madde hükümleri 9’uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre **yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile beşinci fıkradaki suçlardan hükümlü olup, başka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlüler** hakkında da uygulanır.

(11) **Tutuklular hakkında** bu madde hükümlerine göre **karar vermeye soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında mahkeme yetkilidir.**” (Ayrıca bkz. İnfaz Yönetmeliği, m. 72).

Kural olarak “*Görüşme sırasında; hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmaya ilişkin olarak kendilerinin tuttukları kayıtlar incelenemez, hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz*” (İnfaz Kanunu, m. 59, f. 4) ise de, f. 5’de bu kurala **istisna** getirilmiştir. Söz konusu hükme göre,

“Türk Ceza Kanununun 220’nci maddesinde ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan **mahkûm olanların avukatları ile görüşmelerinde**, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne, **terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve tâlimat verildiğine** veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli **mesajlar iletildiğine** ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle; **görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tutukları kayıtlara elkonulabilir** veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.”

Söz konusu fıkra da belirtilen tedbirlere, ancak **belirli suçlardan dolayı mahkûm olup da cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlülerle** ilgili olarak karar verilebilir.

Bu suçlar sırasıyla şu şekilde belirlenmiştir:

- a) TCK, m. 220’de tanımlanan suç örgütü kurma veya yönetme, suç örgütüne üye olma, suç örgütüne yardım suçları,
- b) TCK, m. 302 ilâ 308’de tanımlanan “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar”,
- c) TCK, m. 309 ilâ 316’da tanımlanan “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar”,
- ç) TCK, m. 317 ilâ 325’de tanımlanan “Milli Savunmaya Karşı Suçlar”,
- d) TCK, m. 326 ilâ 339’da tanımlanan “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk”,
- e) Terörle Mücadele Kanunu, m. 3’de sayılan “Terör suçları”,
- f) Terörle Mücadele Kanunu, m. 4’te sayılan “Terör amacı ile işlenen suçlar”,
- g) Terörle Mücadele Kanunu, m. 6’da tanımlanan “Açıklama ve yayınlama” suçları,
- h) Terörle Mücadele Kanunu, m. 7, f. 2 ve devamında tanımlanan *terörizmin veya terör örgütünün propagandası* suçu.

Hatta, bu maddeye onuncu fıkra olarak eklenen hükümle istisnaların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, bu maddedeki hükümlünün avukatıyla yapacağı görüşmenin gizliliğini ortadan kaldırmaya yönelik hükümler, **yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin avukatla yapacağı görüşmeler bakımından da uygulanacaktır.**

Bu suçlar arasında, söz konusu madde metniyle ihdas edilen tedbirlerin uygulanması amacıyla telifi kabil olmayan suçların bulunduğu, kuşkusuzdur. Bu çerçevede, Terörle Mücadele Kanunu’nda tanımlanan açıklama ve yayma (m. 6) ile terörizmin veya terör örgütünün propagandası (m. 7, f. 2 vd.) suçları, örnek olarak gösterilebilir.

Bu sayılan suçlardan birinden dolayı mahkûm olup da ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin avukatları ile yaptıkları görüşmelerle,

- a) *toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmüş olması,* veya,

- b) **terör veya suç örgütünün yönlendirilmesi, bu örgüt mensuplarına emir ve talimat verilmesi, mesajlar iletilmesi,** gerekir.

Hangi suçtan dolayı hükümlü olursa olsun, ceza infaz kurumunda bulunan bir kişinin avukatıyla yaptığı görüşme ile toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, izaha muhtaç bir durumdur. Bununla murat edilen, şayet bir suçun işlenmesine yönelik plan hazırlanması, bir suç işlemeye azmettirme ise, bu fiillerin avukat bakımından da suç oluşturacağı kuşkusuzdur. Şayet böyle bir tespit mevcut ise, özellikle avukat hakkında da adli soruşturma başlatılmış olması gerekir.

Özellikle terör veya suç örgütü yöneticiliğinden dolayı hükümlü bulunan kişilerin avukatları aracılığıyla örgüt mensuplarına emir ve talimatlar vermesi, siyasi birtakım kararların alınmasına müdahalede bulunması ve hatta bütün topluma mesaj göndermesi, günlük hayatımızda karşılaşılan bir

durumdur. Bir avukatın müdafilik görevinin sınırlarını aşarak, savunma amacı dışında bazı bilgi ve mesajları örgüt mensuplarına iletmesi, bir yetkinin kötüye kullanılması örneğini oluşturur.

Avukatın, terör veya suç örgütü yöneticiliğinden dolayı hükümlü bulunan bir kişinin örgütün mensuplarına emir ve talimatlar vermesine aracılık etmesi fiilinin, örgüt üyesi olarak sorumluluğunu gerektirdiği kuşkusuzdur. Bu durumda sorun, hükümlüden ziyade, bir kamu görevi yapan avukat bakımından söz konusudur ve yetkisini kötüye kullanan bu avukat bakımından bir tedbir alınması yoluna gidilebilir. Ancak bunun için, avukat hakkında adli soruşturma sürecinin başlatılmış olmasının gerekli olduğunu ve bu yönde bir kanuni düzenleme yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Herhangi bir suçun işlenmesine yönelik olarak bulunulan somut tespite dayalı olarak adli soruşturma süreci başlatılmadan, aralarında hiçbir ayırım yapmaksızın, hükümlüyle görüşmek isteyen ve görüşen bütün avukatların “şüpheli” muamelesine tabi tutulması, hukuken kabul edilemez. Şayet böyle bir tespit mevcut ise, hükümlü ile yaptığı görüşmede görev ve yetkisini kötüye kullanan bir avukat yüzünden aynı hükümlü ile görüşme yapmak isteyen diğer bütün avukatların şüpheli nazarıyla bir muameleye tabi tutulması da, hukuken tasvip edilemez.

Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi, 28.2.2024 tarihli ve 2020/1142 bireysel başvuru sayılı kararında; başvurunun avukatı ile yapacağı telefon görüşmelerinin üç ay süreyle teknik araçlarla sesli ve görüntülü olarak kaydedilmesi, ayrıca bireysel yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla personel görevlendirilmesinin, hükümlünün devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak suçu dolayısıyla ceza infaz kurumunda bulunması ve PKK terör örgütüne üye olmaktan dolayı hükümlü olan kişilerin örgütsel dayanışma kapsamında açlık grevi başlatmaları, bu eylemin haberleşme araçları vasıtasıyla ve hükümlülerin görüşmelerinde verilen talimatlarla ülke geneline yayılmış olması dolayısıyla hükümlü hakkında öngörülen İnfaz Kanunu m. 59, f. 5 kapsamındaki tedbirin Anayasaya uygun olduğuna hükmetmiştir (pn. 18 ila 22).

Söz konusu kararda avukatın faaliyetleri bakımından herhangi bir belirleme veya gerekçelendirme bulunmamaktadır.

İnfaz Kanunu, m. 59, f. 5’de belirtilen sebeplerin varlığı halinde, hakim veya mahkemenin tedbir olarak verebileceği kararlar, şu şekilde sıralanmıştır:

Cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlünün;

- avukatlarıyla görüşmelerinin teknik cihatta sesli veya görüntülü olarak kayda alınması,
- avukatlarıyla yapacağı görüşmeler sırasında bu görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulması,
- avukatlarıyla yapacağı görüşme sırasında birbirlerine verdikleri belge ve kayıtlara el konulması,
- avukatlarıyla yapacağı görüşmelere gün ve saat itibarıyla sınırlama getirilmesi.

Dikkat edilmelidir ki, İnfaz Kanunu, m. 59, f. 5’deki düzenleme itibarıyla, bu tedbirler, hükümlünün aralarında herhangi bir ayırım yapılmaksızın avukatlar ile yapacağı bütün görüşmeler bakımından uygulanabilecektir. Herhangi bir hukuka aykırı davranışı tespit edilmemiş olan bir avukatın görevini icra bağlamında bir hükümlü ile yapacağı görüşmenin, hakim veya mahkeme kararına dayalı olarak da olsa, infaz görevlilerince izlenmesini ve kayda alınmasını, görüşme için beraberinde getirdiği evrakın ve hatta, yaptığı görüşme sırasında tuttuğu notların **infaz görevlilerince incelenmesini** gerektiren bu düzenlemenin, hukukiliğini savunmak mümkün değildir. Aslında bu düzenleme ve uygulama ile, avukatlık mesleğinin icrası suretiyle öğrenilen sırrın gizliliği ihlâl edilmiş olmaktadır.

İnfaz Kanunu, m. 59, f. 5’deki tedbirlere ilişkin kararın uygulanması, süre ile sınırlı tutulmuştur. Bu tedbirlere üç ay süre ile karar verilebilir. Bu süre zarfındaki uygulama göz önünde bulundurularak, tedbir kararının devamına veya kaldırılmasına karar verilir. Daha önce verilen kısıtlama kararının yenilenebilmesi için, önceki kararın uygulandığı süre zarfında bir ihlâl

Ziyaret sırasında **kurum güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlere** riayet edilmesi gerekir. Bu çerçevede, kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silâhlar kuruma sokulamaz. **Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez** (İnfaz K, m. 86, f. 1, 2).

2) Hükümlülerin Dışarıyla Haberleşmesi

Hapis cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlü, infaz kurumu dışındaki kişilerle **mektuplaşabilir, faks veya telgraf yoluyla haberleşebilir**. Hükümlünün mektup, faks ve telgraf yoluyla haberleşmesinin ücretleri kendisince karşılanır. Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle,

gerçekleşmesini aramak gerekir. Daha önceki kararın uygulanma sürecinde herhangi bir ihlâl gerçekleşmemiş ise, İnfaz Kanunu, m. 59, f. 5'de zikredilen kısıtlamaların uygulanmasına ilişkin karar yenilenemez. Hatta verilen tedbir kararının uygulanma sürecinde, cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlü ile avukatları arasındaki görüşmeler bakımından herhangi bir hukuka aykırılık tespitinde bulunulmaz ise, üç aylık süre dolmadan da tedbir kararının kaldırılmasına karar verilebilir (İnfaz Kanunu, m. 59, f. 6).

Yukarıda da belirttiği gibi, bu tedbirler, cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlünün belirli bir avukatla değil, vekaletnamesi olsun veya olmasın genel olarak herhangi bir avukatla yapacağı görüşmeler ile ilgili olarak uygulanabilir. Keza İnfaz Kanunu, m. 59, f. 5'deki düzenleme itibarıyla, bu tedbir, hakkında karar verilen hükümlünün belirli bir davası veya uyuşmazlığı ile sınırlı olarak uygulanamaz.

Bu tedbirlerin uygulanması sürecinde, ilgili hükümlü ile görüşme yapmak üzere infaz kurumuna başvuran herhangi bir **avukatın beraberinde getirdiği** ve savunmaya ilişkin olduğunu beyan ettiği **belge ve dosyalar, infaz kurumu görevlileri tarafından incelenebilir ve gerektiğinde bunlara el konulabilir**. Keza, avukatın hükümlü veya tutuklu ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak tuttuğu kayıtlar incelenebilir ve gerektiğinde bunlara da el konulabilir (İnfaz Yönetmeliği, m. 72, f. 2, bent e). Kamusal bir görev ifa eden avukatın bu tür bir muameleye tabi tutulması, hukuken tasvip edilemez.

Ancak Anayasa Mahkemesi, İnfaz Kanunu, m. 59, f. 5 hükmünün iptali talebini reddetmiştir (24.7.2019, E. 2018/73, K. 2019/65). Söz konusu kararda bu hükmün Anayasaya uygunluğu, sadece özel hayata saygı hakkı (m. 13, 20) çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmiştir (pn. 95 ilâ 100). Keza, söz konusu hükmün Anayasanın adil yargılanma hakkını düzenleyen 36. maddede ilgisinin olmadığı yönünde değerlendirmede bulunulmuştur (pn. 100). Bu değerlendirmenin tutarsız olduğunu belirtmek gerekir. Söz konusu düzenlemenin infaz kanununda yer almasının sebebi, hükümlülerle ilgili olmasıdır. Ancak, avukatla görüşmesine kısıtlama getirilen kişi, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü de olsa, bir hakkın kullanılması, bir yargılama faaliyetinin icrası bağlamında bir avukat yardımıyla yararlanma ve avukatla görüşme ihtiyacı hisseden kişidir. Bu itibarla söz konusu hükmün hak arama hakkını kısıtlayıcı bir yönünün olduğu görmezlikten gelinemez.

İnfaz Kanununun 59. maddesinin beşinci ve devamı fıkralarında, belirli suçlardan mahkûm olup da ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin avukatla görüşmelerinin gizliliğinin kaldırılmasının koşulları ve usulü belirlendiği için, bu hükümlerin uygulanmasıyla, herhangi bir hukuka aykırı davranışı bulunmayan avukatın da mesleği gereğince kendisine sağlanan güvencelerden yararlanamaması sonucu doğmaktadır.

(Tutuklu veya cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlünün avukatla görüşmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. <https://izzetozgenc.com/data/contents/tutuklu-veya-hukumulun-avukatla-gorusmesinin-gizliliğinin-ihlali-ve-sinirlendirilmesi-sorunu-uzerine-v2.pdf>)

gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda **elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilir** (İnfaz K, m. 68, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m.76).

Hükümlünün infaz kurumu dışındaki kişilerle **mektup, faks veya telgraf yoluyla haberleşmelerinin içeriği kurum tarafından denetlenir** (İnfaz K, m. 68, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m. 76, f. 2)^{290, 291}. Ancak, “*hükümlü tarafından resmî*

²⁹⁰ “Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöeltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren mektup, faks ve telgraflar hükümlüye verilmez. Hükümlü tarafından yazılmış ise gönderilmez.” (İnfaz K, m. 68, f. 3; İnfaz Yönetmeliği, m. 76, f. 3).

Nitekim **Anayasa Mahkemesi**, ceza infaz kurumunda bulunan bir hükümlünün başka bir infaz kurumunda bulunan bir arkadaşına göndermek istediği mektubun bazı bölümlerinin Cezaevi Disiplin Kurulu tarafından kısmen sakıncalı görülmüş olması dolayısıyla sakıncalı görülen yerlerin sansürlenmesi suretiyle alıcısına gönderilmesine karar verilmiş olması olayında, bir hak ihlali olmadığı yönünde karar vermiştir (20.5.2015 tarihli ve 2013/1201 bireysel başvuru sayılı Karar, RG: 10 Ağustos 2015/29441).

Buna karşılık, Anayasa Mahkemesi, bir hükümlüye başka bir hükümlü tarafından gönderilen ve gönderen hükümlünün bulunduğu infaz kurumu disiplin kurulu tarafından içeriğinde yer verilen suç işlemeye yönelik ifadelerin sansürlendiği mektubun, gönderilen hükümlünün bulunduğu infaz kurumundaki disiplin kurulu tarafından, aynı gerekçelerle, hükümlüye verilmemesine ve imhasına karar verilmiş olması olayında, bir hak ihlali olduğu yönünde karar vermiştir (10.8.2015 tarihli ve 2013/1822 bireysel başvuru sayılı Karar, RG: 10 Ağustos 2015/29441).

Ancak, mektup içeriğinin bütünüyle sakıncalı görülmesi dolayısıyla imhasına karar verilmesiyle bir hak ihlalinin doğmadığı kabul edilmiştir (4.7.2018 tarihli ve 2015/15698 bireysel başvuru sayılı Karar; 3.7.2018 tarihli ve 2015/16792 bireysel başvuru sayılı Karar; 3.7.2018 tarihli ve 2015/2103 bireysel başvuru sayılı Karar; 3.7.2018 tarihli ve 2015/4505 bireysel başvuru sayılı Karar; 3.7.2018 tarihli ve 2015/10703 bireysel başvuru sayılı Karar; 27.6.2018 tarihli ve 2015/16260 bireysel başvuru sayılı Karar; 12.6.2018 tarihli ve 2015/4503 bireysel başvuru sayılı Karar; 23.5.2018 tarihli ve 2015/18879 bireysel başvuru sayılı Karar).

²⁹¹ Anayasa Mahkemesi’nin 26.1.2023 tarihli ve 2018/37713 BB sayılı kararına konu teşkil eden olayda, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan B’nin bir yakınına göndermek istediği mektubun, Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu tarafından, içeriğinde PKK terör örgütünü açıkça öven ve örgütün propagandasını yapan sözlerin bulunduğu gerekçesiyle alıcısına gönderilmemesine karar vermiştir.

Ayrıca, operasyon sırasında öldürülen bir terör örgütü mensubunun ailesine hitaben yazdığı ve yakını aracılığıyla bu kişilere ulaştırmak istediği bu mektupta geçen aşağıdaki sözler nedeniyle B hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda, suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapma veya yaptırma eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle, İnfaz Kanunu, m. 37 (f. 1) ve 44 (f. 3) hükümlerine istinaden, 11 gün hücreye koyma cezası verilmesine karar vermiştir:

“Bazı ölüm çeşitleri vardır, 3 günlük yas sonrası yaşam kendini doğal akışına bırakır ama kimi ölüm çeşitleri vardır tarihi ile uyumlu ve ahenkli bir şekilde kendisini yarınlara taşır, abideleşir, destanlaşır. Tarihin kendisi olup tarih yaratır. İşte rodi yoldaşımızda tıpkı batmayan güneşimizin binlerce çocuğu gibi abideleşti. İşte rodi yoldaşımız kısa zaman diliminde bunları başarmış ve layıkıyla nirvanalaşmıştır. Bunun için sizler yani sizler annesi ve babası kardeşleri ve tüm Marine halkı ile beraber rodi yoldaşımızla ne kadar gurur duymanız hep bir tarafı eksik kalır o hepimizin eserdir bizler yoldaşımızı mücadele çizgimizde ölümsüzleştireceğiz. Marine halkımızın ve tüm kürt halkının başı sağolsun diyorum. Rodi ve cudi gibi yol-

daşlarımız olduğu müddetçe özgür yaşama olan inancımız daha da büyüyecektir. Biz onların yoldaşları olarak onların kahramanlıklarını yaşamın her alanına sirayet etmesi için var gücümüzle mücadelemizi güçlü kılacağız. Her ne kadar Rodi yoldaşımızla hiçbir tanışıklığım, selamlaşmam olmamış olsada birbirimizi hiç görmemiş olsakta amaçtaki ve hedefteki birlik-teliğimiz ve bu uğurda nirvanaya ulaşmış olması tüm yoldaşlarımızın belleklerinde yer edindiği gibi belleğimin önemli yerini mesken tutmuştur. Rodi yoldaşımızın son nefesini verdiği coğrafyada bulunuyor olmamız devrim yolunda yükümüzü dahada dahada ağırlaştırmıştır. Onun özlemini hayalini ve amaçlarını gerçekleştirme yolunda mücadele azmimiz ve kararlılığımız her zamankinden dahada fazla olacaktır. Geride bıraktığı devrim bayrağını layıkıyla taşıyıp devrimle taclandırma arayışımız sürekli olacaktır."

Anayasa Mahkemesi, Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu tarafından verilen söz konusu kararların, aşağıdaki gerekçe ile, hukuka uygun olduğu ve bu kararların verilmesiyle B bakımından herhangi bir hak ihlalinin gerçekleşmediği değerlendirilmesinde bulunmuştur:

"Başvurucu, mektubunda PKK terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan ve kolluk güçlerince yapılan operasyonda öldürülen bir örgüt mensubunu yüceltmış; bu kişinin ölümsüzleştiğini belirten ve örgüt içindeki pozisyonu itibarıyla gurur duyulması gereken biri olduğunu ifade etmiştir. Bundan başka başvuru, mektupta, ölen örgüt mensubunun hayallerini ve amaçlarını gerçekleştirmek için mücadele azmi ve kararlılığı içinde olacaklarını belirtmiş; bahis konusu örgüt mensubunun eylemlerini kahramanlık olarak vasıflandırmıştır." (pn. 23)

"... 5275 sayılı Kanun'da düzenleme altına alınan *suç örgütlerinin propaganda faaliyetlerini yapma* disiplin suçu 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan terör örgütünün propagandasını yapma suçu ile karıştırmamak gerekir. Bu ikisinin bir ve aynı şey olduğunu kabul etmek, disiplin suçu adli bir cezanın verilmesi şartına bağlar ki böyle bir yorumun disiplin suçunun konulma amacı ve koruduğu değer ile bağdaştırılması mümkün olmaz. Bu nedenle *suç örgütlerinin propaganda faaliyetlerini yapma* disiplin suçu, ceza infaz kurumlarının güvenliği ve disiplini çerçevesinde özerk bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır." (pn. 24)

"5275 sayılı Kanun'da öngörülen *suç örgütlerinin propaganda faaliyetlerini yapma* disiplin suçu, sadece terör örgütlerinin propagandasının yapılmasını değil her tür suç örgütünün ceza infaz kurumunda propagandasının yapılmasını düzenlemektedir. Söz konusu suç örgütünün silahlı bir örgüt olması mümkün olduğu gibi silahsız bir örgüt olması da mümkündür. Bu noktadan hareket edildiğinde *suç örgütlerinin propaganda faaliyetlerini yapma* disiplin suçunun sadece bir terör örgütünün şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterme veya övme ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmeyle sınırlandırılması mümkün değildir. Örgütsel motivasyonu güçlendirmek, örgüte bağlılığı canlı tutmak, örgütün amaçlarını gerçekleştireceği ümidini aşılacak, örgütün korkutuculuk gücünü yaymak, örgütsel eylemleri yüceltmek, örgütün kurucu, yönetici veya üyelerini övmek amacıyla yapılan, ceza infaz kurumlarının güvenliği ve disiplini tehdit eden, mahkûmların ıslahı amacı ile çatışan faaliyetlerin tamamının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmelidir." (pn. 25)

"Başvuru konusu mektup, PKK terör örgütünün silahlı dağ kadrosunda yer aldığı anlaşılan ve kolluk güçlerinin operasyonu sırasında öldürülen bir örgüt mensubunu ve eylemlerini öven, ölenin eylemlerini *kahramanca* olarak vasıflandıran bir içerikte olup ölen kişinin şiddet içeren eylemlerini açıkça kutsamakta ve yüceltmektedir. Başvurucunun mektubu, örgütsel motivasyonu güçlendirmeyi ve örgüte bağlılığı canlı tutmayı sağlamayı amaçladığı açıktır. Bu nedenle başvuru konusu dokümanın suç örgütünün propagandasının yapılması için elverişli olduğu değerlendirilmiştir."

"... Bir eylemin disiplini bozduğu ve düzenli yaşamın sürdürülmesini önlediği değerlendirilirken disiplin cezalarının amacının da dikkate alınması gerekir. Disiplin cezaları sadece disiplin tesisini değil disiplinsizliğin ve zarar ihtimalinin ortadan kaldırılmasını da amaçlamaktadır. Buradan çıkan sonuca göre kişilerin disiplinsizliğe neden olma potansiyeline sahip eylemlerinin de yaptırıma tabi tutulması gerekmektedir." (pn. 27)

makamlara veya savunması için **avukatına** gönderilen mektup, faks ve telgraflar denetime tâbi değildir. Bu iletiler, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir.” (İnfaz K, m. 68, f. 4; İnfaz Yönetmeliği, m. 76, f. 4).

İnfaz Kanununun 68. maddesine 7328 sayılı Kanunla eklenen fıkrada²⁹², hükümlünün bu iletişim içeriklerinin gizliliğini sınırlandıran düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

“Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkûm olan veya tehlikeli hâlde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen veya bu hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilir veya fiziki olarak saklanabilir. Bunlar, amacı dışında kullanılamaz, kanunda açıkça belirtilen hâller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz, herhangi bir soruşturma veya kovuşturmayla konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinir veya imha edilir. Silme veya imha işlemi Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir. Bu fıkra hükmü dördüncü fıkra bakımından uygulanmaz.” (f. 5)

“Bunun yanında bir hapis cezasının veya özgürlükten yoksun bırakan benzer bir yaptırımın amacı ve meşruiyeti; toplumu suça karşı korumak, bununla bağlantılı olarak mahkûmların ıslahını sağlayabilmektir. Mahkûmların ıslahı ise ancak kişilerin suç işlemesinin önüne geçilmesi ve düzenli bir hayat sürdürmelerini alışkanlık hâline getirmelerinin sağlanmaya çalışılmasıyla mümkün olabilecektir. Bu bağlamda mahkûmların ıslah amacını zorlaştıracak ve düzenli yaşamın sürdürülmesini önleyecek davranışlardan kaçınma yükümlülükleri vardır.” (pn. 28)

“... Örgütsel motivasyonu güçlendirmeyi ve örgüte bağlılığı canlı tutmayı sağlamayı amaçladığı tespit edilen başvuru konusu dokümanın ceza ıslah amacını zorlaştıracığı, mahkûmun toplum içine döndüğünde hukuka saygı göstermesi, yaşamını kendi kendine sürdürebilme isteği ve yeteneği kazandırılması amacına uygun düşmeyeceği değerlendirilmiştir.” (pn. 29)

“Sonuç olarak disiplin cezasına konu eylemin mahkûmların ıslah amacını, ceza infaz kurumunda düzenli bir yaşamın sürdürülmesini ve güvenliğin sağlanmasını zorlaştıracak ve kurumda disiplini bozacak nitelikte bir eylem olduğu değerlendirilmiştir. Dolayısıyla başvurunun ceza infaz kurumunda bulunmasının gerektirdiği sorumluluğa uygun davranmaması nedeniyle verilen cezanın zorunlu bir ihtiyacı karşıladığı, başvuru yöntemden beklenen fayda ile ceza infaz kurumundaki disiplinin sağlanması arasındaki dengenin sağlandığı değerlendirilmiştir. Öte yandan Ceza İnfaz Kurumu idaresinin takdir payı ile birlikte değerlendirildiğinde başvurucuya eylemi nedeniyle verilen hücreye koyma disiplin cezasının orantılı da olduğu, bu nedenlerle müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmadığı kabul edilmiştir.” (pn. 30)

²⁹² Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların kayıt ve silinmesine ilişkin olarak 5275 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.” (İnfaz Yönetmeliği, m.76, f.5)

Görünüşte “güvence” izlenimi oluşturan söz konusu düzenlemeyle, esasında, hükümlünün avukatıyla olan iletişiminin denetlenmesinin yolu açılmış olmaktadır. İçeriğine muttali olunmadan bir mektubun kayda alınmasının mümkün olmadığı ve bir mektubun fiziki olarak saklanması muhatabına ulaşmayacağı anlamına geldiği, izahtan varestedir.

Hükümlüler, ceza infaz kurumu dışındaki kişilerle, **telefonla da görüşebilirler**²⁹³. Ancak bu görüşme, kurumun kontrolündeki ücretli telefonlar üzerinden yapılabilir. Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin “**telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt mensubu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir.**” (İnfaz K, m. 66, f. 1)²⁹⁴. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ise, “**ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilirler.**” (İnfaz K, m. 66, f. 2). Başka bir ifadeyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin telefon görüşmeleri infaz kurumu yetkililerince dinlenememekte ve kayıt altına alınamamaktadır²⁹⁵.

Mevzuatımız, hükümlülerin dışarıdan kişilerle internet ortamında örneğin e-posta yoluyla haberleşmesine izin vermemektedir (Bkz. İnfaz K, m. 67).

Bütün bu hükümler, “**tutukluluk haliyle uzlaşır nitelikte**” olmaları itibarıyla, **tutuklular** hakkında da uygulanabilecektir (İnfaz K, m. 116). Ancak belirtmek gerekir ki, tutukluların ziyareti ve haberleşmesiyle ilgili olarak Kanunda ilave özel hükümlere yer verilmiştir (İnfaz K, m. 114, f. 2, 3, 5). Buna göre;

*“Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde tutuklular, kurumun bu husustaki genel düzenine uymak suretiyle ziyaretçi kabul edebilirler. Ancak soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkeme, soruşturmanın veya davanın selameti bakımından **tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir** veya bu hususta **kısıtlamalar koyabilir.**” (f. 2)*

*“Tutukluların **yazılı haberleşmeleri ile telefonla görüşmeleri**, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemesince **kısıtlanabilir.**” (f. 3)*

Ancak,

“Tutuklunun müdafii ile olan haberleşmesine ve kurum düzeni çerçevesinde temas ve görüşmelerine hiçbir suretle engel olunamaz ve kısıtlamalar konulamaz.” (f. 5)

²⁹³ Hükümlülerin telefonla görüşme hakkı, İnfaz Yönetmeliğinin 74. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

²⁹⁴ Dinlenen ve kayıt altına alınan bu telefon görüşmelerinin akıbetinin ne olacağı hususunda mevzuatımızda bir hüküm bulunmaması, bir eksikliktir.

²⁹⁵ Hükümlüler, telefonla iletişim hakkını, kurumun kontrolündeki ücretli telefonlar üzerinden kullanabilir. Ancak, “**Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık, salgın hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılırlar.**” (İnfaz K, m. 66, f. 3).

J. Hükümlülerin Çalıştırılması

Çağdaş ceza infaz sisteminin amacı, hükümlünün sosyalleştirilmesini teşvik etmek, yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırarak hükümlüyü ıslah etmek, böylece özel ve genel önlemeyi sağlamak, toplumu suça karşı korumaktır.

Hükümlünün ıslahı ve yeniden sosyalleştirilmesi bakımından çalışmanın büyük bir önemi vardır. Bu nedenle, hükümlülerin mesleki eğitimleri ve çalışmaya alıştırılmaları, en önemli ıslah aracı olarak kabul edilmektedir. Ceza infaz kurumundan tahliye edildikten sonra dahil olacağı sosyal çevrede yaşamını idame ettirecek bir meslek sahibi olmak, hükümlünün topluma adapte olmasını kolaylaştıracaktır. Belirtmek gerekir ki, birçok insanın suça yönelmesinin temel nedeni, yasal ve sürdürülebilir bir gelir getirecek işinin olmamasıdır.

Çalışma, hükümlüyü yeniden topluma kazandırmanın en önemli aracı olmanın yanı sıra, kurum düzenini sağlayan önemli etkenlerden biridir. Kurum güvenliği yalnızca fiziksel önlemlerin alınması ile gerçekleşmemektedir (sağlanmamaktadır). Bir amaca hizmet eden bir işle meşgul olmayan ve zamanının büyük bir bölümünü boş geçiren bir hükümlünün depresyona girmesi ve kurum düzenini bozacak davranışlar içerisinde bulunması yüksek ihtimaldir. Çalışma, hükümlünün zamanını olabildiğince yararlı geçirmesine ve bir ücret elde etmesine imkân hazırlayacağı gibi, kişinin kendi öz saygısını yeniden kazanmasına katkıda bulunarak, oldukça önemli psikolojik bir işleve hizmet eder.

Çalıştırmanın amacı, hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecektir meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek ve güçlendirmektir. Çalıştırmada hükümlünün yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları göz önünde bulundurulur.

Türk İnfaz Hukuku sisteminde hükümlülerin çalıştırılmasına ilişkin olarak gerek İnfaz Kanununda gerek İnfaz Yönetmeliğinde hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca hükümlülerin istihdam olanaklarının artırılması ve meslek kazanmaları ile yenilik ve teknoloji transferini sağlamak için İşyurtları Kurumu ile gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe giren, “**İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik**”²⁹⁶ de hükümlülerin çalıştırılması konusunda düzenlemeler içermektedir.

İnfaz Kanununda, hükümlünün çalıştırılması konusu yükümlülüklerine ilişkin bölümde düzenlenmiş ise de, çalışma hükümlü için alelittlak bir yükümlülük olarak kabul edilmemiştir (m. 29). Hükümlünün meslek sahibi olup olmamasına

²⁹⁶ RG: 14 Haziran 2018 - 30451.

göre bir ayırım yapılmıştır. Şayet meslek sahibi ise, hükümlü ancak isteğe bağlı olarak çalıştırılabilir. Buna karşılık, meslek sahibi olmayan hükümlüler, “*kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenmiş*” olması halinde ve cezaevi idaresi tarafından çalışması istendiği takdirde, çalışmakla yükümlü kılınmışlardır (İnfaz K, m. 29, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 81, f. 1).

Tutukluların ise, ancak istekte bulundukları takdirde çalışmalarına izin verilebilir (İnfaz K, m. 114, f. 1).

Hükümlüler kural olarak ancak **infaz kurumu bünyesindeki atölye ve işyurtlarında çalıştırılabilirler.**

Buna karşılık, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış hükümlüler, **kurum dışındaki iş alanlarında çalıştırılabilirler** (İnfaz K, m. 30, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 82, f. 1). Hükümlülerin kurum dışında çalıştırılması, işveren veya temsilcisi ile iş yurdu bulunan kurumlarda iş yurdu müdürü, iş yurdu bulunmayan kurumlarda ise mahalli Cumhuriyet başsavcısının imzalayacağı **protokol** hükümleri **çerçevesinde** mümkündür (İnfaz Yönetmeliği, m. 83, f. 3). Yapılan işbirlikleri neticesinde yürütülen programlarda hükümlülerin en az iki kişiden oluşan ekipler halinde çalıştırılmaları öngörülmüştür (İnfaz Yönetmeliği, m. 83, f. 4).

Kurum dışında çalıştırılan hükümlülerin, çalıştıkları işyerlerinde gece barındırılmalarına izin verilmez. Çalışılan yer kurumlarına yakınsa, geceleri kurumlarına dönmeleri zorunludur. Kurumların bulunduğu yerin dışında bir işyerinde çalıştırılan hükümlülerin gece barındırılmaları, çalıştıkları yere en yakın açık kurumda, bulunmadığı takdirde kapalı kurumun hükümlü ve tutuklularla irtibatı olmayan bir bölümünde sağlanır (İnfaz Yönetmeliği, m. 83, f. 6). Ayrıca hükümlülerin kamu veya özel sektörle yapılan bu işbirliklerinden haksız bir kazanç elde etmelerini engellemek için, kendi veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına ait işyerlerinde çalıştırılması yasaklanmıştır (İnfaz Yönetmeliği, m. 83, f. 2; İşyurtları Yönetmeliği, m. 21, f. 3).

Bu çalışmalarına karşılık hükümlülere “kurum imkanları ölçüsünde” belirlenen **ücret** ödenir (İnfaz K, m. 29, f. 1). Bu ücret, hükümlülerin ürettiklerinden elde edilen gelirden ödenir. Keza bu hükümlüler **sosyal haklardan** yararlandırılırlar (İnfaz K, m. 32, f. 1). Hükümlülerin çalıştırılması hizmet akdine yani bir iş sözleşmesine dayanmadığı için çalışan hükümlü ve tutukluların sigortalılık durumları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. maddesinin (a) bendinde ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre, hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. İnfaz Yönetmeliğinin

de, sadece kurum dışında çalışan hükümlülerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükme yer verilmiştir (m. 83, f. 5). Buna göre, çalışma güvenliği işveren tarafından sağlanmalı ve iş kazası ile meslek hastalıklarından doğan sorumluluk yine işverene ait olacaktır.

İyi hâlli hükümlüler, idare ve gözlem kurulu kararı ile kurum yönetimi tarafından durumlarına uygun **kurum içi hizmetlerde çalıştırılabilirler** (İnfaz K, m. 31, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 84, f. 1). “*Hekim, psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve benzeri mesleklerle sahip olan hükümlülerden; iyi hâl gösterenler, idare ve gözlem kurulu kararıyla, kurumun servislerinde meslekleriyle ilgili görevlere yardımcı veya eğitici olarak çalıştırılabilir*” (İnfaz Yönetmeliği, m. 84, f. 3).

Ayrıca, “*açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilirler.*” (İnfaz K, m. 30, f. 5).

Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitime yönelik olabilir. Ayrıca öğretim kurumlarına veya örgün eğitime devam eden çocuk ile genç hükümlüler, öğretim yılı içinde atölye ve işyerlerinde çalıştırılmazlar (İnfaz K, m. 29, f. 3). Öte yandan çocuk eğitimevinde bulunan hükümlülerin, kurum dışında çalıştırılmaları sırasında kurum görevlilerinin gözetimi ve muhafazası aranmaz (İnfaz K, m. 30, f. 3).

Çocuk hükümlülerin çalıştırılmalarında 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun, 5275 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır (İnfaz K, m. 29, f. 4).

K. Hükümlünün İnfaz Kurumunda Hastalanması

Hapis cezasına mahkûm olup da bilahare “akıl hastası” olduğu anlaşılan kişi, tedavi amacıyla yüksek güvenlikli sağlık kuruluşuna yerleştirilir. Kişinin bu sağlık kuruluşunda geçirdiği süre, “*cezaevinde geçmiş sayılır*” (İnfaz K, m. 16, f. 1).

“Akıl hastalığı” ibaresi, tıbbi bir kavram değildir. Hangi psikiyatrik rahatsızlığın bu kavram kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, “*Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor*”la belirlenir (İnfaz K, m. 16, f. 3).

Keza, bir sağlık kuruluşunda tedavi görmeyi gerekli kılan ve fakat “**hükümlünün hayatı için kesin bir tehlike teşkil**” etmeyen diğer bir hastalık, derhal infaza engel teşkil etmemektedir. Bir hastalığın “**hükümlünün hayatı için kesin bir tehlike teşkil**” edip etmediği, “*Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor*”la belirlenir (İnfaz K, m. 16, f. 3).

Her insan gibi, hükümlünün de sağlık hakkı mevcuttur (İnfaz K, m. 71, f. 1, birinci cümle)²⁹⁷. Ancak, hükümlünün hastalık “*tanısı için muayene ve tedavi*”si, öncelikle infaz kurumu bünyesindeki sağlık biriminde yapılır. Bu muayene ve tedavi, kurum bünyesindeki sağlık biriminde “*mümkün olmaması halinde*,” Devlet veya üniversite hastanelerinde yapılır (İnfaz K, m. 71, f. 1, ikinci cümle; İnfaz Yönetmeliği, m. 96, f. 2, m. 99, f. 2)²⁹⁸.

²⁹⁷ Anayasa Mahkemesinin 14.4.2022 tarihli ve 2018/29836 BB sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, ceza infaz kurumunda **tutuklu** olarak bulunan B, 4.4.2018 tarihinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe göndererek, infaz koruma memurları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını, yüzüne ve vücuduna çok sayıda darbe aldığını, koridorda sürüklendiğini, kurum doktoru tarafından muayene edilerek durumunun tespiti istemesine rağmen bu talebinin yerine getirilmediğini iddia ederek, infaz kurumundaki kamera görüntülerinin izlenmesini, Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek hakkında sağlık raporu düzenlenmesini talep etmiştir.

B ayrıca dilekçesine, oda arkadaşı E’nin olayla ilgili görgüsüne dayalı yazılı beyanlarını eklemiştir. E’nin yazılı anlatımlarında, B’nin odaya getirildiğinde ayağa kalkamayacak hâlde olduğunu, yüzünün sol yanak kısmında şişlik, sırt bölgesinde kızarıklık ve ezikler bulunduğunu, mide bulantısı ve baş dönmesi olduğunu söylemesi üzerine kurum yetkililerinden yardım istediklerini, ancak bu taleplerine kayıtsız kalındığını ifade etmiştir.

Başsavcılık 13.4.2018 tarihli yazısıyla infaz kurumu yönetimden bu iddiaların araştırılmasını talep etmiştir. İnfaz kurumu yönetiminin 16.4.2018 tarihli cevabı yazısında, söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir delil veya emareye ulaşılmadığı yönünde açıklamaya yer verilmiştir.

Başsavcılık, bu iddialarla ilgili olarak başkaca herhangi bir araştırma yapmadan 2.5.2018 tarihinde kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermiştir. B’nin bu karara itirazı, sulh ceza hakimi tarafından reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki gerekçelerle, bu iddialar karşısında etkili soruşturma yapılmadığını kabul ederek, kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir:

“*Ceza infaz kurumunda tutulan bir kişinin şikâyetçi olması hâlinde kötü muameleye maruz kalıp kalmadığının tespiti amacıyla alınan sağlık raporları, değerlendirmeye esas oluşturacak en önemli kanıtlardan biri*”dir. (pn. 32)

“... *başvurucu, yaralanmasının tespiti amacıyla hakkında sağlık raporu alınmasını talep etmiş, ancak Başsavcılık bu yönde bir işlem yapmamıştır. Başvurucunun iddiasının savunulabilir olup olmadığının değerlendirilmesinde en önemli delillerden biri olan sağlık raporu.. Başsavcılıkça temin edilmemiş*”tir (pn. 33; ayrıca bkz. pn. 34, 35).

²⁹⁸ Bu düzenlemelerde sorun, hükümlünün infaz kurumu bünyesindeki sağlık biriminde muayene ve tedavisinin mümkün olup olmadığına hangi merciin karar vereceği hususunda temerküz etmektedir. Hükümlüye ilk tıbbi müdahaleyi yapan, kurum bünyesindeki sağlık biriminde görev yapan tabiptir. Bu tabip, “*hükümlünün sağlık nedeniyle hastaneye sevkine gerek duyduğunda*” durumu bir “*rapor*” halinde infaz kurumu yönetimine bildirecektir (İnfaz Kanunu, m. 80, f. 1; İnfaz Yönetmeliği, m. 99, f. 1). Bu düzenlemelerde, hükümlünün infaz kurumu dışında Devlet veya üniversite hastanesinde tedavi edilebilmesine karar vermeye hangi merciin yetkili kılındığı açık bir şekilde gösterilmemiştir. Bu durumda infaz kurumu yönetiminin yetkisinin, kurum bünyesindeki sağlık biriminde görev yapan tabibin hasta hükümlü ile ilgili olarak düzenlediği rapor üzerine bu hükümlünün hastaneye sevk için gerekli iş ve işlemleri yapmakla sınırlı olduğunu kabul etmek gerekir. Başka bir ifadeyle, kurum sağlık biriminde görev yapan tabip, hasta hükümlünün tedavisinin Devlet veya üniversite hastanesinde yapılması gerektiği yönünde rapor düzenledikten sonra, infaz kurumu yönetimi veya başka herhangi bir merci, bu hastanın tedavisinin infaz kurumu bünyesindeki sağlık biriminde yapılmasına devam edilmesine karar verme yetkisi bulunmamaktadır (172 sayılı Genelge, Üçüncü Kı-

“Bir sağlık sorunu olup da muayene ve tedaviyi reddeden hükümlülerin sağlık veya hayatlarının ciddi tehlike içinde olması veya ceza infaz kurumunda bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı hâlinde”, **rızalarının olup olmadığına bakılmaksızın** ve fakat, “sağlık ve hayatları için tehlike oluşturmamak şartıyla” **muayene ve tedavileri yapılır** (İnfaz Kanunu, m. 82, f. 3 ve atıfta bulunduğu f. 2).

Hapis cezasının infaz kurumunda çekildiği sırada maruz kalınan hastalığın bir sağlık kuruluşunda tedavi görmeyi gerekli kılması halinde, bu tedavi, “**resmî sağlık kuruluşlarının hükümlülere ayrılan bölümlerinde**” icra edilir (İnfaz K, m. 16, f. 2)^{299,300}. Başka bir ifadeyle, infaz sürecinde yakalanan hastalık, kural olarak **infaza ara verilmeyi gerektirmemektedir**. Hastalık halinde de infaza devam, esastır.

Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, kasten işlenen suçlarda üç yıl veya daha az süreli, taksirli suçlarda beş yıl veya daha az süreli hapis cezasının infazına başlanmış ise, hükümlünün yakalandığı **hastalığın sürekli bir tedaviyi gerektirmesi halinde, infaz durdurulabilmektedir** (İnfaz K, m. 17, f. 4).

Keza “sürekli hastalık” dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından bir hükümlüyle ilgili olarak özel af yetkisinin kullanılması suretiyle hapis cezasının infazına son verilebilir (Anayasa, m. 104, f. 16).

L. Hükümlülerin İzinli Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılması

Mahkum oldukları hapis cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlüler, çeşitli sebeplerle izinli olarak infaz kurumunun dışına çıkarılabilmektedirler (İnfaz K, m. 93 vd.).

sım, Birinci Bölüm, A, 1). Bu durumda infaz kurumu yönetiminin ve ilgili Cumhuriyet başsavcılığının görevi, hükümlünün sevk edileceği sağlık kuruluşunu ve hükümlüye refakat edecek kişileri belirlemekten ibarettir (172 sayılı Genelge, İkinci Kısım, Birinci Bölüm, C, 1, 2).

²⁹⁹ İnfaz Yönetmeliğinin “**Hükümlülerin hastaneye sevk ile hastanelerde muayene ve tedavileri**” başlıklı 99. maddesi hükmü şu şekildedir:

“**MADDE 99-** (1) Hükümlünün sağlık nedeniyle bir hastaneye sevkine gerek duyulduğunda durum, cezaevi tabibi tarafından bir raporla derhal kurum en üst amirine bildirilir.

(2) Kurumda tedavisi mümkün olmayan hastalığı bulunan hükümlülerin muayene ve tedavileri **devlet ve üniversite hastanelerinde** gerçekleştirilir. Hükümlülerin yatarak tedavileri bunlar için ayrılan hükümlü koşullarında yapılır. Hükümlü koşulu yoksa tedavileri dış güvenlikten sorumlu güvenlik görevlileri tarafından gerekli önlemler alınarak hastanelerin diğer birimlerinde yapılır.

(3) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevi hükümlülerinin kurum dışındaki yatarak tedavileri, tedavi eden kurumun bulunduğu yerdeki kurumun iç güvenlik görevlileri gözetiminde ve hükümlü odası dışındaki bir bölümde yapılır.

(4) Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilir.

³⁰⁰ Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlü ile ilgili tıbbi müdahaleler, kural olarak infaz kurumunda yapılır. Bunun mümkün olmaması halinde, tıbbi müdahale, “**tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinde** yapılır. Bu durumda hükümlü, sağlık kuruluşunun “**tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koşullarında**” tutulur (İnfaz K, m. 25, f. 1, bent 1).

a) Hükümlü, **belirli bir mazeret sebebiyle** izinli olarak infaz kurumu dışına çıkarılabilir. Hükümlü, kendisiyle belirli derecede akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişilerin ölümü ya da “*yaşamsal (hayatî) tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinde*” belirli süre ve koşullarla izinli olarak infaz kurumu dışına çıkarılabilir (İnfaz K, m. 94).

Tutuklular bakımından ise, Kanunda **özel mazeret izni hükümlerine** yer verilmiştir (İnfaz K, m. 116, f. 2 vd.; İnfaz Yönetmeliği, m. 114, f. 8).

b) Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere, “*aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verilebilir.*” (İnfaz K, m. 95).

c) Mahkûm oldukları hapis cezasını infaz kurumunda çekmekte olup da “koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin verilebilir.” (İnfaz K, m. 96)³⁰¹.

İşaret etmek gerekir ki, “*izinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır.*” (İnfaz K, m. 93, f. 2; İnfaz Yönetmeliği, m. 113, f. 2)^{302,303,304}.

³⁰¹ İnfaz Kanunundaki bu hükümlerin yanı sıra, İnfaz Yönetmeliğinde çeşitli sebeplere bağlı izinlerle ilgili olarak ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir (İnfaz Yönetmeliği, m. 113 ilâ 117).

³⁰² “COVID-19” salgını tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında, 14.4.2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunla, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin belirli bir zamana kadar “izinli” olarak infaz kurumu dışına çıkarılması sağlanmıştır (İnfaz Kanunu, Geçici m. 9). Ancak bu düzenlemede, “izinli” olarak infaz kurumu dışına çıkarılan hükümlülerin denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması gerekli görülmemiştir. Bu suretle, on binlerce hükümlü, **herhangi bir koşul belirlenmeksizin, tamamen denetimsiz olarak**, barınabileceği bir evi olup olmadığı, geçimini sağlayabileceği bir maddi imkanının bulunup bulunmadığı araştırması yapılmaksızın, **serbest** bırakılmıştır.

Hatta, “izinli” sayılarak kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkarılabilen hükümlü sayısını artırabilmek için, bir kısım disiplin suçlarının bile görmezlikten gelinmesinin yolu açılmıştır (İnfaz K, Geçici madde 9, f. 1).

Bu bağlamda,

- İnfaz kurumunda uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve hatta satmak (İnfaz K, m. 46, f. 7, bent b),

- Kasten yaralama (İnfaz K, m. 46, f. 7, bent p),

gibi fiiller, göz ardı edilen disiplin suçlarına örnek olarak gösterilebilir.

Keza, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla İnfaz K, m. 105/A hükümlerine göre denetimli serbestlik tedbiri uygulaması çerçevesinde toplumsal ortamda cezalarını çekmekte olan hükümlüler de, “izinli” sayılarak bu denetimin dışına çıkarılmıştır.

Bu kanuni düzenleme ile, yeni suçların işlenmesine davetiye çıkarılmıştır. Yeni suçların işlenmesinin ve yeni mağduriyetlerin mümkün olduğunca önüne geçmek amacıyla, medeni ül-

kelerde örneği bulunmayan bu düzenlemeden bir an önce vazgeçilmesi gerekir. Bunun yolu, bir an önce üç maddelik bir kanun çıkarılarak, “izinli” statüde sokağa salınan hükümlülerden en azından özel tehlikeliliği olanların denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasını sağlamaktır. Bu suretle, söz konusu Kanununun kabulünde dahil bulunan kişilerin, işlenen suçlardan dolayı sorumlu olmaktan kurtulması da sağlanmış olur.

Demokratik toplumların en önemli özelliklerinden birisi, kamusal iş ve işlemlerle sonuçlarının şeffaf olmasıdır, kamunun bilgisinden saklanmamasıdır. Bu itibarla, cezalandırmakla güdülen amaçların ne ölçüde gerçekleştiği konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için, izlenen infaz politikalarının sonuçları konusunda da kamunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, 7242 sayılı Kanunla infaz kurumlarından herhangi bir denetime tabi tutulmaksızın “izinli” olarak salıverilen hükümlülerden bu “izin” sürecinde tekrar suça karıştığı için yeniden infaz kurumuna döndürülenlerin sayıları ile ilgili olarak kamunun bilgilendirilmesi gerekir.

³⁰³ 7242 sayılı Kanunla on binlerce hükümlünün “izinli” olarak infaz kurumu dışına çıkarılmış olmasıyla bağlantılı diğer bir sorun, bu hükümlülerin izin süresi sonunda **infaz kurumuna geri dönmeleri** halinde ortaya çıkacaktır. 7242 sayılı Kanunla, “izinli” olarak herhangi bir gözetim ve denetimi olmaksızın serbest bırakılan bu **on binlerce hükümlünün** önemli bir kısmının sürekli olarak yapılan uzatmalarla en geç **31.7.2023** tarihi itibarıyla infaz kurumlarına geri dönmesi gerekecektir. Bu hükümlülerin tekrar infaz kurumlarına geri dönmelerini sağlamanın taşıdığı güçlük, izahtan varestedir.

TCK’nın 292. maddesinde hükümlünün kaçması fiili suç olarak tanımlanmış iken; İnfaz Kanununda, izinli olarak veya sair sebeplerle serbest bırakılan hükümlünün infaz kurumuna geri dönmemesi halinde dahi söz konusu 292. maddesine göre cezalandırılması yönünde hükümlere yer verilmiştir (m. 58, f. 3; madde 97, f. 2; m. 105/A, f. 8; geçici m. 9, f. 5).

Oysa, 292. maddede tanımlanan suç, mahiyeti itibarıyla ancak **icraî** davranışla işlenebilir. Bu suçu oluşturan fiil, **kaçmaktır**. Hükümlü, **ceza infaz kurumundan kaçtığı takdirde** bu suç oluşur. Keza hükümlü, çeşitli sebeplerle ve fakat **görevlilerin (jandarmanın) gözetimi altında** infaz kurumu dışına çıkarılabilmektedir; örneğin tedavi amacıyla hastaneye kaldırılabilmekte, duruşmaya çıkarılmak üzere mahkemeye gönderilebilmektedir. Hükümlünün **gözetimi altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçması halinde de**, TCK, m. 292’de tanımlanan suç oluşur.

Belirtmek gerekir ki, örneğin Alman Ceza Kanununda, hükümlünün kaçmasına yardım etmek, kaçmasını sağlamak fiilleri suç olarak tanımlanmış (§ 120) olmakla birlikte; hükümlünün salt kaçması, kendisinin cezalandırılmasını gerektirmemektedir. Bu durumda bir **şahsi cezasızlık sebebinin** olduğu kabul edilir. Buna karşılık, söz konusu Kanunda birden fazla hükümlünün cebir veya tehdit kullanarak firar etmesi, suç olarak tanımlanmıştır (§ 121). Bazı kanunlarda ise, örneğin izinli olarak infaz kurumu dışına çıkarılmış olan hükümlünün süresinde kuruma geri gelmemesi de suç olarak tanımlanmıştır (Fransız CK, m. 434; Polonya CK, m. 242).

Türk Ceza Kanununda ise, suç siyaseti olarak orta yol izlenmiştir. Kaçmak fiili suç olarak tanımlanmış iken, örneğin “izinli” olarak ve fakat, **görevlilerin gözetimi altında olmaksızın** serbest bırakılan hükümlünün iznin bitmesine rağmen tekrar infaz kurumuna geri dönmemesi, suç olarak tanımlanmış değildir. Bu durum, tutuklu veya hükümlünün sadece disiplin sorumluluğunu gerektirir.

Bu bağlamda Anayasa Mahkemesinin 27.12.2018 tarihli ve E. 2018/153, K. 2018/119 sayılı kararında gerekçe olarak yer verilen şu açıklamalar önemlidir:

“Ceza infaz kurumundan izin verilerek ayrılmasına müsaade edilen hükümlünün izinden süresi içerisinde dönmemesi ile firar eden hükümlünün hukuki statülerinin farklı olduğu açıktır. İzinden süresinde dönmeme fiilinin ihlal ettiği hukuki yarar ile ceza infaz kurumundan kaçma fiilinin ihlal ettiği hukuki yarar birbirinden farklıdır. Bu kapsamda kanun koyucunun izinden süresinde dönmemeyle ceza infaz kurumundan firar etme suçlarının maddi unsurlarını farklı olarak düzenlemesi eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.” (RG: 15 Ocak 2019/30656).

M. Adli Para Cezasının İnfazı

Hapis cezası gibi, adli para cezası da kural olarak **derhal infaz** olunur. Ancak, **hükümlünün askerlik görevi, mahkum olduğu adli para cezasının infazı**

İnfaz Kanununun TCK, m. 292’de tanımlanan suça ilişkin hükümlerin uygulama alanını genişletmeye matuf hükümleri, gerek suçta kanunilik ilkesi bağlamında gerek düzenleme içerikleri itibarıyla sorunludur.

³⁰⁴ Hükümlünün “izinli” olarak infaz kurumu dışında geçirdiği süre zarfında yeni bir suç işlemesi halinde, bu suçu işledikten sonra teslim olmaması sebebiyle firarda geçirdiği sürenin infazdan sayılmaması gerektiği hususunda, mevzuatımızda hüküm bulunmamaktadır.

İnfaz Kanunundaki “izin” sürelerinin kısıtlılığı sebebiyle, “izinli” olarak ve fakat, bazı durumlarda herhangi bir denetim ve gözetim uygulaması olmaksızın, infaz kurumu dışına çıkarılan hükümlünün bu süre zarfında yeni bir suç işlemesi halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda Kanunda hüküm bulunmaması, bir eksiklik olarak değerlendirilmeyebilir. Ancak, 7242 sayılı Kanunla **aylarca devam edecek “izinli”lik durumu** ihdas edilince, bu “izin” süresince hükümlünün **yeni suç işlemesi**, bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır.

Bu durumda sorunu iki evre bakımından değerlendirmeye tabi tutmak gerekir. Birinci evreyi hükümlünün 15.04.2020 tarihinde “izinli” olarak infaz kurumundan çıktıktan sonra kasıtlı suçu işlediği tarihe kadar geçen süre oluşturmaktadır. İkinci evreyi ise, “izinli” olan hükümlünün kasıtlı suçu işledikten sonra, teslim olmaması halinde, yakalanıncaya kadar ve her halde izin süresi sonuna kadar geçen süre oluşturmaktadır.

Koşullu salıverilen hükümlünün denetim süresi zarfında kasıtlı suç işlemesi halinde, koşullu salıverilme kararı geri alınmaktadır (İnfaz K, m. 107, f. 12). Bu durumda hükümlü, “*sonraki suçu işlediği tarihten itibaren başlamak*” üzere cezasını infaz kurumunda çekecektir (İnfaz K, m. 107, f. 13, bent a). Bu düzenlemeye göre, hükümlünün koşullu salıverildikten sonra denetim sürecinde kasıtlı suçu işlediği tarihe kadar geçen süre, infazdan sayılacaktır.

Keza, koşullu salıverme öncesinde hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasını infaz kurumu dışında çekmekte olan hükümlünün bu süreçte kasıtlı bir suç işlemesi halinde, tekrar infaz kurumuna alınacaktır (infaz K, m. 105/A, f. 7). Bu düzenleme itibarıyla, hükümlünün yeni suçu işlediği tarihe kadar denetimli serbestlik tedbiri altında infaz kurumu dışında geçirdiği süreyi infazdan saymak gerektiği hususunda kuşku bulunmamaktadır.

Gerek koşullu salıverilen gerek denetimli serbestlik uygulamasıyla infaz kurumu dışına çıkarılan hükümlünün denetim sürecinde yeni suçu işledikten sonra teslim olmayıp yakalanamaması halinde, bu arada geçen süre infazdan **sayılmamaktadır**.

Bu hükümler dikkate alındığında, 15.04.2020 tarihinde “izinli” olarak ve fakat denetimsiz bir şekilde serbest bırakılan hükümlünün infaz kurumundan çıktıktan sonra kasıtlı suçu işlediği tarihe kadar geçen sürenin (birinci evrenin) infazdan sayılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Buna karşılık, İnfaz K, m. 93, f. 1, ikinci cümlesi hükmü karşısında, “izinli” olan hükümlünün kasıtlı suçu işledikten sonra, teslim olmaması halinde, yakalanıncaya kadar ve her halde izin süresi sonuna kadar geçen sürenin infazdan sayılamayacağı değerlendirmesinde bulunmak hukuken mümkün değildir. Ancak, bu sürenin infazdan sayılmaması gerektiği hususu açıktır. Bunun için acil bir **kanuni düzenlemeye** ihtiyaç bulunmaktadır. Böyle bir düzenleme bağlamında belirtmek gerekir ki, “kazanılmış hak” kavramının ceza ve infaz hukukunda uygulama yeri bulunmamaktadır.

Bu konularda ayrıntılı bilgi için bkz.ÖZGENÇ, İzzet: *COVID-19 Salgınının Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku ve Milletlerarası Hukuk Alanında Sebebiyet Verdiği veya Verebileceği Sorunlar ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri*, in: TÜBA Covid-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu, Covid-19 Salgını Dolayısıyla Ulusal veya Uluslararası Alanda Ortaya Çıkan/Çıkabilecek Hukuki Sorunların Çözümüne Yönelik Öneriler Raporu, Türkiye Bilimler Akademisi yayını, Ankara, Temmuz 2020, sh. 11 vd., 23 vd.

bakımından bir erteleme sebebi oluşturmaktadır. Bu durumda adli para cezasının infazı, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonraya ertelenir. Ancak, bu süre zarfında ceza zamanaşımı işlemez (İnfaz K, m. 118, f. 1).

Adli para cezasına ilişkin hükmün kesinleşmesi üzerine, Cumhuriyet savcısı tarafından hükümlüye bir “**ödeme emri**” tebliğ olunur³⁰⁵. Hükümlü, bu “*ödeme emri*”nin tebliğinden itibaren **otuz gün** içinde adli para cezası miktarını Devlet hazinesine öder (İnfaz K, m. 106, f. 2). Adli para cezasının tamamı Devlet hazinesine def’aten ödenir. Ancak, hükümde, adli para cezası takside bağlanmış ise, ilk taksitin bu otuz günlük süre içinde; diğer taksitlerin ise, mahkûmiyet kararında belirtilen süreler zarfında, ödenmesi gerekmektedir.

Mahkûmiyet kararında adli para cezası takside bağlanmamış olsa bile; hükümlü, “bir aylık” (doğrusu, otuz günlük) süre içinde adli para cezasının üçte birini Devlet hazinesine ödediği takdirde, Cumhuriyet savcısından geri kalan üçte ikilik kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilmesini isteyebilir. Bu talep üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından hükümlüye gerekli izin verilir (İnfaz K, m. 106, f. 6)³⁰⁶.

Adli para cezasının tamamının veya taksitlerinden birinin süresinde ödenmemesi halinde, hükümlü kamuya yararlı bir işte çalıştırılır. Cumhuriyet savcısı tarafından taksitler halinde ödenmesine izin verilen adli para cezasının taksitlerinin ödenmemesi durumunda da, hükümlü kamuya yararlı işte çalıştırılır. Belirtmek gerekir ki, Cumhuriyet savcısı tarafından taksitler halinde ödenmesine izin verilen adli para cezasının ilk taksitinin süresinde ödenmemesi hâlinde, “*verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır*” (İnfaz K, m. 106, f. 6, son cümle). Keza, mahkûmiyet kararında takside bağlanmış adli para cezasının taksitlerinden birinin süresinde ödenmemesi, diğer taksitleri de muaccel hale getirir (TCK, m. 52, f. 4). Bunun ifade ettiği anlam şudur: Taksitlerden birinin ödenmemesi dolayısıyla izlenecek yöntem, ödeme tarihi henüz gelmemiş olan taksitler bakımından da izlenecektir.

6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce hükümlü adli para cezasını ödemediği takdirde, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık

³⁰⁵ “... ödeme emrinin tebliği, hükümde gösterilen adrese yapılır. Hükümlü, adres değişikliklerini mahkemeye veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirmekle yükümlüdür. Aksi hâlde hükümde gösterilen adreste yapılan tebligat geçerlidir.” (İnfaz Yönetmeliği, m. 144, f. 1).

³⁰⁶ “**Hükümde taksitlendirilme yapılmış ise** cezanın artık buna göre infaz edilmesi gerektiğinden, **Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir taksitlendirilme yapılamayacaktır.** Ancak hükümde adli para cezası takside bağlanmamış ise Cumhuriyet Başsavcılığınca bir aylık süre içinde adli para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verebilecek, ilk taksidin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalacaktır.” CGK, **17.9.2013**, E. 2012/12-1522, K. 2013/373.

gelen gün miktarınca hapsediliyordu³⁰⁷. 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle zorlama hapsi uygulamasından vazgeçilmiştir.

6545 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre ise, adli para cezasını ödeme-yen hükümlü, **bir gün** karşılığı olarak **iki saat** süreyle **kamuya yararlı bir işte çalışmakla** yükümlüdür (İnfaz K. m. 106, f. 3). Ancak, çekin karşılıksız çıkması dolayısıyla 5941 sayılı Çek Kanununun 5. maddesi hükmüne istina-den adli para cezasına mahkum olan kişi, şayet mahkum olduğu adli para cezasını ödemezse, “*bu ceza, ... kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir*” (5941 sayılı Çek Kanunu, m. 5, f. 11).

Hükümlünün hangi işte çalışacağı **Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**nce belir-lenecektir. Hükümlü, bu çerçevede bir günde en az **iki**, en fazla ise **sekiz saat** çalıştırılabilecektir (İnfaz K. m. 106, f. 3).

6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, hükümlünün kamuya yararlı bir işte ne kadar süreyle çalıştırılacağına dair bir sınırlama getirilmemiştir. Bu durum kar-şısında, hükümlünün kamuya yararlı bir işte ne kadar süreyle çalıştırılacağı, mahkûm olduğu adli para cezasının TCK’nın 61. maddesindeki usul ve sıraya göre belirlenmiş olan **sonuç gün unsuru** dikkate alınmak suretiyle belirlenecek-tir. Durumu çeşitli örneklerle açıklayabiliriz:

Örnek 1. Kişi, hakaret suçunu işlemesi dolayısıyla (200 gün X 100 TL =) 20.000 TL adli para cezasına mahkum edilmiştir (TCK, m. 125, 52, 61). Hükümlü, bu parayı Devlet hazinesine ödemediği takdirde, 200 gün karşılığı olarak (200 gün X 2 saat =) 400 saat süreyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılacaktır.

Örnek 2. Kişi, güveni kötüye kullanma suçunu işlemesi dolayısıyla bir yıl hapis ve (500 gün X 100 TL =) 50.000 TL adli para cezasına mahkûm edilmiştir (TCK, m. 155, 52, 61). Hükümlü, bu parayı Devlet hazinesine ödemediği tak-dirde, 500 gün karşılığı olarak (500 gün X 2 saat =) 1.000 saat süreyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılacaktır.

Örnek 3. Kişi, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlemesi dolayısıy-la 15 yıl hapis ve (5.000 gün X 100 TL =) 500.000 TL adli para cezasına mahkûm edilmiştir (TCK, m. 188, 52, 61). Hükümlü, bu parayı Devlet hazi-nesine ödemediği takdirde, 5.000 gün karşılığı olarak (5.000 gün X 2 saat =) 10.000 saat süreyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılacaktır. Bu hükümlünün, bir günde sekiz saat çalıştırılacak olursa, 1250 gün süreyle; bir günde iki saat çalıştırılacak olursa, 5.000 gün süreyle, kamuya yararlı bir işte çalıştı-rılması gerekmektedir.

³⁰⁷ Bu hususa ilişkin olarak Kitabımızın önceki basılarındaki açıklamalara ve 9. bası, sh. 727 vd.na bakılabilir.

Her ne kadar 6545 sayılı Kanunla İnfaz Kanununun 106. maddesinin onbirinci fıkrasına “kamuya yararlı işte çalışmanın süresi” ibaresi eklenmiş ise de, maddede hükümlünün azami olarak ne kadar süreyle kamuya yararlı işte çalıştırılabileceği-ne dair düzenleme yoktur. Aşağıda açıklanan azami hapis sürelerine ilişkin yedinci fıkra hükmünü, kamuya yararlı işte çalışma ile ilgili olarak uygulama imkânımız bulunmamaktadır. Böyle bir uygulamaya yorum yöntemlerinin hiçbirisi imkân vermemektedir. Kanaatimizce, onbirinci fıkradaki söz konusu değişiklik, kamuya yararlı işte çalışma ile ilgili azami bir süre öngörüsüne dayanmamakta, aşağıda açıkladığımız mahsup sorununu çözmeye ilişkin bulunmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, bir hükümlünün 10 yıl gibi veya daha fazla bir süreyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasını sağlamak fiilen mümkün değildir. Bu nedenle, 6545 sayılı Kanunla İnfaz Kanununun 106. maddesinde alelacele yapılan değişikliğin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir³⁰⁸.

İşaret edelim ki, “*hükümlü, ... kamuya yararlı işte çalıştığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı (Devlet hazinesine) öderse ... kamuya yararlı işte çalıştırılma sona erer.*” (İnfaz K, m. 106, f. 8).

Kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde, hükümlü hapsedilecektir. Ancak, bu hapis, **adli ceza olarak hapis cezası değildir**. Bu hapis, mahiyeti itibarıyla **disiplin hapsidir**^{309, 310}. Bu “*hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanamaz.*” (İnfaz K, m. 106, f. 9). Keza, adli para cezasının infazı bağlamında kişi hapsedilmiş olsa bile, “*hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adli para cezasıdır.*” (İnfaz K, m. 106, f. 9).

Hükümlü bu çerçevede hapsedildiğinde, “**hapis süresi üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkûmiyet hâlinde (ise) bu süre beş yılı geçemez.**” (İnfaz K, m. 106, f. 7). Ancak, “*hükümlü, hapis yattığı ... günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı (Devlet hazinesine) öderse hapisten çıkartılır*” (İnfaz K, m. 106, f. 8).

Söz konusu sürelerin geçmesine rağmen, hapis yatılan ve –şayet çalışılmışsa– kamuya yararlı işte çalışılan sürelerin adli para cezasını tamamıyla karşılamaması halinde, adli para cezasının geri kalan kısmı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine istinaden tahsil edilir (İnfaz K, m. 106, f. 11)³¹¹.

³⁰⁸ Bu gözden geçirme ve yeni bir düzenleme yapma faaliyeti kapsamında İnfaz Kanununun 106. maddesinin yanı sıra TCK’nın 52. maddesinin ilgili hükümlerinin de ele alınması gerekmektedir.

³⁰⁹ Bu nedenle, 6545 sayılı Kanunla değiştirilen İnfaz Kanununun 106. maddesinin üçüncü fıkrasında “hapis cezası” ibaresinin kullanılması doğru olmamıştır.

³¹⁰ Bu hapsin infazı bağlamında hükümlü, “*açık ceza infaz kurumu*”na konulur (İnfaz K, m. 106, f. 9).

³¹¹ Bu durumda “*geri kalan adli para cezasının tahsili için ilâm, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük mal memuruna verilir.*” (İnfaz K, m. 106, f. 11).

Fiili işlediği sırada çocuk olan hükümlü, mahkûm olduğu adli para cezasının infazı bağlamında hapsedilemez ve dolayısıyla bu hükümlülere kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğü tahmil edilemez. Bu durumda adli para cezasının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi yoluna gidilecektir (İnfaz K, m. 106, f. 4). Dikkat edilmelidir ki, fiili işlediği sırada çocuk olan hükümlü hakkında mahkûmiyet hükmünün kurulduğu tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olabilir. Bu hükümlüler de mahkûm oldukları adli para cezasının infazı bağlamında kamuya yararlı işte çalıştırılmayacaklardır. Bu yönü itibarıyla, TCK'nın 50. maddesinin kısa süreli hapis cezası yerine kamuya yararlı işte çalışma seçenek yaptırımını uygulanmasına imkân tanıyan hükmü (f. 1, bent f, f. 3) ile İnfaz Kanununun 106. maddesinin söz konusu düzenlemesi arasında bir çelişki bulunmaktadır.

Ekskurs 2. İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi

I. Türkiye'de infaz kurumlarında bulunan **hükümlü** sayısında tarihsel süreç içinde sürekli artış gözlemlenmektedir. Bu artışlar sebebiyle infaz kurumlarının kapasitesinin üzerine çıkılması karşısında, mülga **765 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlükte olduğu dönemde**, çözüm olarak, zaman zaman genel af veya özel koşullu salıverilme kanunları çıkarılması ve bu suretle çok sayıda hükümlünün infaz kurumlarından tahliyesi yoluna gidilmişti. Ancak, bu tahliyeler sadece geçici bir süre için "çözüm" oluşturabilmişti.

II. Yeni **5237 sayılı Türk Ceza Kanununun** 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girişi dolayısıyla lehe kanun uygulamaları bağlamında infazın durdurulması (5252 s. TCK Yürürlük Kanunu, m. 10) yoluna gidilmek suretiyle, infaz kurumlarından tahliyeler gerçekleşmiş olmasına rağmen, infaz kurumlarındaki hükümlü sayısında sürekli bir yükseliş gözlemlenmiştir.

5.4.2012 tarihli ve 6291 sayılı Kanunla³¹² İnfaz Kanununda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikte, mahkûm olduğu hapis cezasının önemli bir kısmını infaz kurumunda çeken ve fakat henüz koşullu salıverilme aşamasına gelmemiş olan hükümlülerin cezalarının kalan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak toplumsal ortamda infazının yolu açılmıştır (İnfaz K. m. 105/A, Geçici madde 3). Bu değişiklik gereğince, ceza infaz kurumlarından tahliyeler gerçekleşmiştir.

24.1.2013 tarihli ve 6411 sayılı Kanunla³¹³ İnfaz Kanununa yeni bir geçici madde eklenmiştir (Geçici madde 4). Bu geçici madde ile İnfaz Kanununun 105/A maddesinin uygulama alanı genişletilmiştir. Bu geçici madde hükmü gereğince, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak üzere ceza infaz kurumlarından tahliyeler gerçekleşmiştir.

³¹² RG: 11 Nisan 2012/28261.

³¹³ RG: 31 Ocak 2013/28545.

Yeni Türk Ceza Kanununda, suçların karşılığında öngörülen cezalar, mülga 765 sayılı TCK'ya nazaran çok daha yüksektir. Keza, mülga 765 sayılı TCK'nın sisteminde kişi mahkum olduğu hapis cezasının **beşte ikisini** infaz kurumunda iyi halli olarak çektiği takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilmekte idi. Buna karşılık yeni İnfaz Kanununun 14.4.2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki sisteminde ise, ilk defa suç işlemiş olan kişinin mahkum olduğu hapis cezasının infazı sürecinde koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için mahkum olduğu cezanın **üçte ikisini** infaz kurumunda iyi halli olarak çekmesi gerekmektedir. Buna karşılık, mükerrerler ise mahkum oldukları cezanın **dörtte üçünü** infaz kurumunda iyi halli olarak çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir. 7242 s. Kanunla yapılan değişiklikten sonra, hapis cezasına mahkum olan hükümlerin infaz kurumunda çekmeleri gereken sürelerde sınırlama yapılmasına rağmen, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü sayılarında sürekli artış olmaktadır.

Eski Kanunun yürürlükte olduğu dönemde örneğin kasten öldürme suçundan dolayı mahkum olunan hürriyeti bağlayıcı cezanın en fazla 12 yılını infaz kurumunda çektiği takdirde koşullu salıverilmeden yararlanarak tahliye edilebilmekte idi. Buna karşılık, yeni TCK'nın sisteminde ise, kasten öldürme suçundan mahkum olan kişi, 24 yıl infaz kurumunda cezasını çektikten sonra, iyi halli ise, koşullu salıverilmeden yararlanabilmektedir.

Lehe kanun hükümlerinin uygulanması sebebiyle, ancak 2010 ve sonrası yıllarda yeni TCK hükümlerine göre mahkum olan hükümlülerin infaz kurumuna girdiğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenledir ki, 2010 ve sonrasında infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısındaki artış oranı, önceki yıllara nazaran daha yüksektir.

İnfaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısı, Türkiye'deki infaz kurumlarının kapasitesinin üzerindedir.

İnfaz Kanununda yapılan söz konusu değişikliklere rağmen, infaz kurumlarındaki yoğunluk, sorun olmaktan çıkarılamamıştır. Zaman içerisinde infaz kurumlarının kapasitesinin artırılması da bu sorunu çözememiştir.

Acil önerimiz, Türk ceza hukukunda suç karşılığında öngörülen yaptırımlarla, bunların infaz rejimlerinin bir bütün olarak ele alınıp yeniden düzenlenmesinin sağlanmasıdır. Aksi takdirde, yapılan mevzi düzenlemelerle sadece geçici bir rahatlama sağlanabilecek ve kısa bir süre sonra infaz kurumlarındaki hükümlü sayısı tekrar yükselişe geçecektir.

İnfaz Kanununda yapılan söz konusu değişikliklere dayalı olarak gerçekleşen tahliyelerle, ancak geçici bir süre için infaz kurumlarında yer açılması sağlanmıştır. Kalıcı çözümler oluşturmadığımız sürece, kısa bir zaman zarfında, yine aynı sorunu aktüel olarak yaşamaya mahkûmuz.

Kalıcı çözüm oluşturulabilmesi için, kapsamlı bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bu konuda yapılan akademik çalışmalarda oluşturulan önerilerin hayata geçirile-

bilmesi için, **Adalet Bakanlığı istatistiklerinde yayımlanmayan, hükümlü ve tutuklulara ilişkin bazı verilerin ilgililerle paylaşılması gerekmektedir.** Örneğin koşullu salıverilmeden yararlanan ve cezasının kalan kısmını halen toplum içinde çekmekte olan hükümlü sayısı bilinmemektedir. Bu hükümlülerden kaç kişinin yeniden suç işleyerek tekrar infaz kurumlarına döndüğüne dair bilgimiz de bulunmamaktadır. Bu bilgi eksikliği, Devlet bakımından da söz konusudur.

Sistemimizde, infaz aşamasında ve hatta hüküm kesinleştikten sonra hükümlünün mağdurla ilişkisi tamamen kesilmektedir. Oysa **infaz aşamasında da etkin pişmanlıktan yararlanılablmesinin ve özellikle hükümlü ile mağdurun barışmasını sağlayacak yolların açık tutulması gerekmektedir.** Halen cari infaz sistemimizde bu yollar tamamen kapalıdır.

Ancak, bu yolların işletilebilmesi için mahkemelerin iş yükünün de artırılması gerekmektedir.

Bu yöntemle, özellikle cinsel suçlardan mahkûm olan faille mağdur arasında bilahare meşru zeminde evliliğin gerçekleşmesine rağmen, infaza devam edilmesinin ortaya çıkardığı şikayetlerin de sonlandırılması mümkün bulunmaktadır³¹⁴.

III. Adalet Bakanlığında dolaylı yollarla temin edilen sınırlı istatistiki bilgilere göre, **31.5.2022** tarihi itibarıyla **ceza infaz kurumlarında** bulunan toplam kişi sayısı **317.368** idi. Bu sayı, **3.7.2022** tarihi itibarıyla **322.129** olmuştur.

Aradan geçen **33 günlük** zaman zarfında ceza infaz kurumlarının mevcudu, **4.761 kişi artmıştır.**

Ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısında, 2.7.2022 gününden 3.7.2022 gününe kadar meydana gelen, yani **bir günlük artış sayısı, 492'dir.**

Keza, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, **2.5.2023** tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında, 315.197'si hükümlü, 41.390'ı tutuklu, toplam **356.587** kişi bulunmaktadır³¹⁵. Buna göre ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısı, 3.7.2022 tarihinden 2.5.2023 tarihine kadar her ay ortalama **3.458** kişi artmıştır. Bu, korkunç bir durumdur!

Nüfus bakımından bizimle olan paralelliği dolayısıyla seçilmiş bir örnek olarak **Almanya'da ceza infaz kurumlarında** bulunan toplam kişi (hükümlü ve tutuklu) sayısı, 30.6.2021 tarihi itibarıyla **59.056** iken, 30.6.2022 tarihi itibarıyla

³¹⁴ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “Die aktuellen Probleme in der Praxis des Türkischen Strafvollstreckungsrechts”, in: Dr.Dr.h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Editörler: F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoglu, A. Sözüer, F. Turhan, Ankara, Mayıs 2018, sh. 1177 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: *Yaptırım Teorisi ve İnfaz Siyaseti*, in: TÜBA Günce, sayı 60, Mayıs 2019, sh. 30 vd.; ÖZGENÇ, İzzet/BAYRAKTARLI, İhsan Yılmaz: *İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXIII, Ocak 2019, sayı 1, sh. 129 vd.

³¹⁵ <https://cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/10052023091554istatistik-1.pdf> (Erişim tarihi. 5.6.2023).

56.557 olmuştur³¹⁶. Buna karşılık, bizim ceza infaz kurumlarımızda **1.7.2022** tarihi itibarıyla bulunan **belirli suçlardan** hükümlü ve tutuklu sayıları aşağıdaki şekildedir:

Başta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti olmak üzere “**uyuşturucu suçları**”:

Hükümlü sayısı: 91.794; Tutuklu sayısı: 14.483; Toplam: **106.277 kişi**.

Hırsızlık:

Hükümlü sayısı: 67.875; Tutuklu sayısı: **3.557**; Toplam: **71.432 kişi**.

Mükerrerlik bakımından ilk göz önünde bulundurulması gereken suç hırsızlık olmasına rağmen, bu suçtan tutuklu olanların sayısının azlığı dikkat çekmiştir.

İnsan öldürme:

Hükümlü sayısı: 33.956; Tutuklu sayısı: 5.528; Toplam: **39.484 kişi**.

Yağma:

Hükümlü sayısı: 25.214; Tutuklu sayısı: 2.350; Toplam: **27.564 kişi**.

Adalet Bakanlığının ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu gelişme karşısında duyarsız kalmaya devam etmesi, hukuk zemininde çözüm üretme çabası göstermemesi, “çıkış yolu” olarak 2023 yılında, adı ne olursa olsun, bir **AF** tasarrufunda bulunmaya mecbur kılacaktır.

Söz konusu istatistiki verilere göre, ceza infaz kurumlarında bulunup da **30.6.2022** tarihi itibarıyla (İnfaz K, m. 105/A hükümlerine göre) “denetimli serbestlik tedbiri” uygulaması çerçevesinde infaz kurumlarından çıkarılan hükümlü sayısı **172.899**’dur.

Bu istatistiki veriler arasında, bu hükümlülerden ne kadarının bir yıllık denetim süresi zarfında yeniden suç işlediği için tekrar infaz kurumuna döndüğüne dair bilgi bulunmamaktadır.

Söz konusu istatistiki verilerden öğrendiğimiz kadarıyla, 30.6.2022 tarihine kadar koşullu salıverilenlerden sadece **358 hükümlü** ile ilgili olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulaması yapılmaktadır. Oysa İnfaz Kanununun düzenlemesine göre, koşullu salıverilenlerle ilgili olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulaması kuraldır.

Söz konusu istatistiki veriler arasında, bu tarih itibarıyla koşullu salıverilmiş olup da cezasını toplumsal ortamda çekmekte olan hükümlü sayısına ve keza, bu hükümlülerden kaç kişinin yeniden suç işlediği için tekrar infaz kurumuna döndüğüne dair bilgi bulunmamaktadır.

³¹⁶ <https://www.prisonstudies.org/country/germany> (Erişim tarihi. 5.6.2023). Almanya’da ceza infaz kurumunda bulunan **yabancı uyruklu** kişi oranının 31.3.2020 tarihi itibarıyla **%25,5** olduğuna dikkat çekmek isterim.

Söz konusu istatistiki verilere göre, 30.6.2022 tarihi itibarıyla, koşullu salıvermeden yararlanarak ceza infaz kurumundan çıkmış olup da **hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan mükerrir hükümlü** sayısı, **32.669**'dur. Ancak bu istatistiki veriler arasında, bu tarih itibarıyla ceza infaz kurumlarında ne kadar ve hangi suçlar bağlamında mükerrir hükümlü bulunduğu dair bilgi bulunmamaktadır.

Söz konusu istatistiki verilere göre, **adli para cezasına mahkum olup da bu parayı ödemediği için kamuya yararlı işte çalışan hükümlü** sayısı 30.6.2022 tarihi itibarıyla **23.225**'dir. Ancak, söz konusu istatistiki veriler arasında, belirli bir zaman zarfında, adli para cezasına mahkum olan hükümlülerden ne kadarının cezasının ödemek suretiyle infaz edildiğine dair bilgi bulunmamaktadır.

Söz konusu istatistiki verilere göre, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup da, denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan sanık sayısı 30.6.2022 tarihi itibarıyla **215**'dir. Ancak, söz konusu istatistiki veriler arasında, belirli bir zaman zarfında,

- a) hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup da denetim süresi henüz devam etmekte olan sanık sayısına,
 - b) bu sanıklardan ne kadarı yeniden suç işlediği için hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının geri alındığına,
- dair bilgi bulunmamaktadır.

Sağlıklı bir yaptırım ve infaz siyasetinin belirlenebilmesi için bütün bu bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bilgileri bütün ısrarlarımıza rağmen Adalet Bakanlığında temin edemiyoruz.

İnfaz Kanunu, geçici madde 6 ve 9 hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine rağmen, **cezasını infaz kurumlarında çekmekte olan hükümlü sayısındaki bu sürekli artış**, zorunlu olarak, yakın bir zamanda bir kanunî düzenleme yapılması sonucunu doğuracaktır. Bu kanunî düzenlemenin, bilimsel verilere dayalı **adil** ve kalıcı **bir infaz düzenlemesi** şeklinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, adına “af” denmese bile, adı ne olursa olsun, **kamu vicdanını rahatsız eder bir surette, infaz kurumlarından hükümlü tahliyelerini sağlayacak ve mahiyeti itibarıyla AF sonucunu doğuracak düzenleme** yapılması yoluna gidilecektir. Bu ise, sürgit sorun mahiyetinde, infaz kurumlarında kısa sürede aynı sorunların tekraren yaşanmasına sebebiyet verecektir.

XV. Güvenlik Tedbiri

Yukarıda da açıkladığımız gibi, cezalandırma ile güdülen asıl amaç, suç teşkil eden bir haksızlığı gerçekleştiren kişinin, bu suçu işlemek dolayısıyla içinde bulunduğu kusurluluk durumundan ibra olmasını sağlamaktır. Hukuk toplu-

mundaki sosyal düzenin idamesi, cezalandırmak ile güdülen amacın bir tezahürü olarak anlaşılmalıdır³¹⁷. Cezanın asıl özelliği, *kefare*t teşkil etmesidir. Bir başka ifadeyle, kişinin işlediği suçtan dolayı kusurunun örtülmesidir; kısacası, kişinin resosyalize edilmesidir. Böylece, belli bir cezaya mahkûm olan kişi, bu cezanın infazıyla, önce, işlediği suçtan dolayı sorumlu olduğunun bilincine kavuşmalıdır. Cezanın infazıyla kişi, gerçekleştirdiği haksızlıktan dolayı sorumluluk altında olduğunu aktüel bir şekilde hissedecek ve böylece, kusurundan ibra olacaktır³¹⁸. Kısaca, cezanın asıl amacı -kural olarak- *müşbet anlamda özel önlemedir*; suç işleyen kişinin yeniden topluma kazandırılmasıdır; toplum açısından zararsız ve güvenilir bir kişi haline getirilmesidir³¹⁹.

Kişi işlediği hukuka aykırı fiil dolayısıyla kusurlu bulunmasa bile; bu fiil, haksızlık özelliğini korumaktadır. Bu nedenle, gerçekleştirdiği hukuka aykırılıktan dolayı kusurunun olmadığı durumlarda kişi cezalandırılmayacaktır. Çünkü, ceza hukukunun temel prensiplerinden birisi, *kusursuz ceza olmaz (nulla poena sine culpa)* ilkesidir³²⁰. “Kusur ilkesi” olarak nitelendirilen bu evrensel hukuk kuralı, kusurlu olmayan kişiye ceza verilemeyeceğini ifade etmektedir³²¹. Ancak, fiil, haksızlık ve dolayısıyla, suç teşkil etme özelliğini devam ettirdiği için; bu durumda, her ne kadar kişi hakkında cezaya hükmedilemeyecek ise de, şayet bir tehlikelilik hali söz konusuysa, *güvenlik tedbiri* uygulanabilecektir³²².

³¹⁷ Buna karşılık *Jakobs*, hukuk toplumundaki sosyal düzenin idamesinin teminini, cezalandırmakla güdülen yegane amaç olduğu fikrindedir (JAKOBS, Das Schuldprinzip, sh. 7). Keza *Önder*, cezanın uygulanmasına duyulan gerekliliği; Devletin korunmasına, Devletin varlığını idame ettirmesine duyulan ihtiyaçla izah etmeye çalışmaktadır (ÖNDER, Ayhan: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, cilt III, 1989, sh. 8, 14).

³¹⁸ BOCKELMANN, Paul: *Vom Sinn der Strafe*, in: Heidelberger Jahrbücher V, sh. 25; aynı yazar: *Schuld und Sühne*, 1957 (30 sayfeden ibaret bütün eser); SCHMIDHAEUSER, Eberhard: *Vom Sinn der Strafe*, 2. Auflage, 1971, sh. 43 vd.; WALDER, Hans: *Die Vernehmung des Beschuldigten*, Hamburg, 1965, sh. 18; RÖSSNER, Dieter: *Autonomie und Zwang im System der Strafrechtsfolgen*, in: Festschrift für Jürgen Baumann, 1992, sh. 269 vd.

³¹⁹ Arth. KAUFMANN, Schuldprinzip, 116 vd., 127 vd., 201 vd., 208 vd.; aynı yazar: *Recht und Sittlichkeit*, sh. 44; aynı yazar: *Dogmatische und kriminalpolitische Aspekte des Schuldgedankens im Strafrecht, ein Beitrag zur Strafrechtsreform*, in: Juristenzeitung, 1967, sh. 553 vd. (özellikle sh. 556 vd.); aynı yazar: *Schuldprinzip und Verhältnismäßigkeits-grundsatz*, in: Festschrift für Richard Lange, 1976, sh. 27 vd.; aynı yazar: *Schuld und Prävention*, in: Festschrift für Rudolf Wassermann, Darmstadt/Neuwied, 1985, sh. 889 vd. (893 vd.); aynı yazar: *Unzeitgemäße Betrachtungen zum Schuldgrundsatz im Strafrecht*, in: Jura, 1986, sh. 225 vd. (229 vd.). Ayrıca bkz. STRATENWERTH, Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips, sh. 28 vd.; ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 124.

³²⁰ *Öztürk*, sözkonusu prensibi “kusursuz suç ve ceza olmaz” şeklinde telâkki etmektedir (ÖZTÜRK, Ceza Hukuku, sh. 22 vd., sh. 311 vd.). Haksızlık ve kusur arasındaki ayrımı bertaraf eden bu anlayış, kanaatimizce, isabetli değildir.

³²¹ İÇEL/DONAY(3), sh. 76/77; ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 126.

³²² MAURACH/ZIPF I, sh.484/485; NUHOĞLU, sh. 51, 83/84.

Güvenlik tedbiri, işlediği suçtan dolayı kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, suç işleyen kişi hakkında ya da suçun konusu ile veya suçun işlenmesinde kullanılan araçla ilgili olarak uygulanan, koruma veya iyileştirme amacına yönelik ceza hukuku yaptırımıdır³²³.

Bir **ceza hukuku yaptırımı** olan **güvenlik tedbirine** hükmedilebilmesi için, bir **suçun** işlenmesi gerekir. Ancak, bu suçun işlenmesi dolayısıyla kişinin kusurlu olması şart değildir. Bu bakımdan, kişinin işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla kusurlu bulunması halinde, cezaya hükmedilmesinin yanı sıra güvenlik tedbiri de uygulanabilir. Ancak, işlediği suç dolayısıyla kişinin kusurlu addedilmemesi halinde, hakkında cezaya hükmolunamazsa da, güvenlik tedbiri uygulanabilir.

Bu bakımdan kusurluluk, cezalandırılabilirliğin *olmazsa olmaz şartını* (*conditio sine qua non*) oluşturmaktadır. Buna karşılık, güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için, kişinin işlediği suç dolayısıyla kusurlu addedilmesi şart değildir.

Güvenlik tedbiri, suç oluşturan fiili işleyen **kişi hakkında, koruma ve iyileştirme amacıyla** uygulanabilir. Çocuk veya akıl hastası hakkında uygulanan güvenlik tedbirleri bu niteliktedir (m. 56³²⁴, 57).

³²³ Güvenlik tedbiri kavramını münhasıran failin tehlikeliliği ile ilgili olarak açıklayan görüşler için bkz. ARTUK, M. Emin: Emniyet Tedbirleri, in: Argumentum, 23(1992), sh. 355; JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 11; NUHOĞLU, sh. 7 vd.; ÇETİN, Soner Hamza: *Türk Ceza Kanununda Seçenek Yaptırımlar*, Ankara, 2011, sh. 58 vd.

³²⁴ 3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı **Çocuk Koruma Kanununa** göre;

“Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır.” (m. 11).

Koruyucu ve destekleyici tedbirler de söz konusu Kanunun 5’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

“Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;

a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,

d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına,

e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hami-le kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,

Yönelik tedbirdir.” (m. 5, f. 1).

Güvenlik tedbiri, **suç oluşturan fiili işleyen kişinin çevresine ve hatta ailesine karşı korunması amacıyla** uygulanabilir. Çocuklar hakkında uygulanan güvenlik tedbirlerinin bir kısmı bu amaca hizmet etmektedir.

Güvenlik tedbiri, **suç oluşturan fiili işleyen kişiden toplumun korunması amacıyla** uygulanabilir. Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiriyle güdülen amaçlardan birisi budur. Keza, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (m. 53), mükerrirlere özgü güvenlik tedbirleri (m. 58), yabancı suçluların sınır dışı edilmesi (m. 59) ve kısa süreli hapis cezası yerine kişinin muayyen bir süre için “*belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma*”sı (m. 50, f. 1, bent d) ya da belli bir “*ehliyet ve ruhsat belge(s)inin geri alınması..., belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma*”sı (m. 50, f. 1, bent e), bu amaca hizmet eden güvenlik tedbirleridir.

Güvenlik tedbiri, **suç oluşturan fiili işleyen kişinin iyileştirilmesi, eğitilmesi ve ıslahı amacıyla** uygulanabilir. Çocuklara veya akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleriyle güdülen amaçlardan birisi budur. Keza, ve kısa süreli hapis cezası yerine kişi hakkında “*en az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye*” hükmedilmesi (m. 50, f. 1, bent c), bu amaca hizmet eden bir güvenlik tedbiridir³²⁵.

Güvenlik tedbiri, **suçun konusu ile ilgili olarak** da uygulanabilir³²⁶. Suçun konusunun örneğin uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ya da patlayıcı maddenin zararlı veya tehlikeli olması nedeniyle müsadere edilmesi (**eşya müsaderesi** -m. 54-) bu nitelikte bir güvenlik tedbiridir. Keza, **kazanç müsaderesi** (m. 55), bu kategoride mütalaa edilebilen bir güvenlik tedbiridir.

Suçun işlenmesinde kullanılan araçla ilgili olarak da güvenlik tedbiri uygulanabilir. Örneğin **eşya müsaderesi** veya **tüzelkişilere özgü güvenlik tedbirleri** nin bir kısmı (m. 60, f. 2) bu niteliktedir.

³²⁵ Ceza ve güvenlik tedbirleri arasında özellikle eğitcilik, ıslah, iyileştirme, resosyalizasyon yönü itibarıyla mevcut olan benzerlik dolayısıyla, güvenlik tedbirlerinin de bir "ceza" olduğu görüşü ileri sürülmüştür (HAFIZOĞULLARI, Ceza Normu, sh. 234, dn. 4, sh. 243, dn. 26).

³²⁶ Klasik ceza hukuku anlayışında güvenlik tedbirinin ancak suç işleyen *kişi hakkında* uygulanabilecek bir yaptırım olduğu kabul edilmektedir: DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1343; ARTUK, M. Emin: Emniyet Tedbirleri, in: Argumentum, 23(1992), sh. 355; ARTUK/GÖKCEN/ YENİDÜNYA, Genel Hükümler, Üçüncü Bölüm, §5, I, 1; CENTEL, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 60; NUHOĞLU, sh. 9, 65; TOROSLU, sh. 387; SOYASLAN, sh. 634; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 9. bası, sh. 325 vd.; HAKERİ, Genel Hükümler, 14. bası, sh. 572 vd. Ancak, bu anlayış, yaptırım teorisindeki gelişmelere paralel olarak, yeni TCK'nın yaptırım sisteminde terkedilmiştir.

Fuhşa sürüklenen kişi, fuhuş suçunun faili değil, mağduru olduğu için; bu kişi ile ilgili olarak tedavi (terapi) uygulanması, (TCK, m. 227, f. 8) teknik anlamda güvenlik tedbiri değildir (ak-si fikir HAKERİ, Genel Hükümler, 14. bası, sh. 573).

Güvenlik tedbiri, işlenen suçun ağırlığı ile orantılı olarak değil, **tehlikelilik durumu** göz önünde bulundurularak uygulanan bir ceza hukuku yaptırımıdır. Bu yönü itibarıyla güvenlik tedbiri cezadan farklılık arz etmektedir. Zira, güvenlik tedbirinden farklı olarak, işlenen **suçun “ağırlığıyla orantılı”** cezaya hükmolunur.

Yeni TCK’nın 3. maddesine göre; “*Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.*” (f. 1). Bu hükümden, somut olayda verilecek cezanın işlenen **suçun “ağırlığıyla orantılı”** olması gerektiği sonucunu doğru olarak çıkarabiliriz. Ancak, güvenlik tedbiri açısından aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bu bakımdan Kanunun söz konusu hükmü sorunludur³²⁷. Gerçi kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için bir suçun işlenmesi ve işlenen suçun belli bir ağırlık derecesine ulaşması şart olarak aranabilmektedir. Örneğin, mahkumiyetin kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin uygulanabilmesi için, kasten işlenen suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olmak gerekir. Keza, eşya müsadereesine hükmedebilmek için, kasten işlenmiş olan bir suçun varlığı gereklidir.

Suç işleyen kişi hakkında ancak mahkeme kararıyla cezaya hükmolunabilir. Buna karşılık, güvenlik tedbiri açısından her zaman mahkeme tarafından verilmiş bir hükmün varlığına gerek bulunmamaktadır.

Yeni CMK’nın 223’üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre, “*Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur.*” Buna göre, kişi hakkında işlediği suçtan dolayı cezaya değil, güvenlik tedbirine hükmolunabilir. Yaş küçüğü veya akıl hastası olması nedeniyle kişi hakkında sadece güvenlik tedbirine hükmolunması, bu hususa örnek olarak gösterilebilir.

Kişi hakkında işlediği suçtan dolayı cezanın yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunabilir³²⁸. Örneğin, işlediği kasıtlı suçtan dolayı cezaya mahkumiyetin yanı

³²⁷ Bu husus, TBMM Adalet Komisyonunda yeni TCK’na ilişkin müzakereler sırasında tarafımızdan gündeme getirilmiştir. Önerimize göre, söz konusu fıkra metni,

“*Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı cezaya hükmolunur. Keza, işlenen suçun ortaya çıkardığı tehlikelilik durumuna göre güvenlik tedbiri uygulanır.*”

şeklinde düzeltilmelidir. Ancak bu düşünce ve önerimiz, Komisyon tarafından dikkate alınmamıştır.

Bu nedenle doktrinde yeni TCK’nın 2. maddesinin düzenlemesine güvenlik tedbirleri bakımından eleştiri yöneltilmektedir. Bu eleştirilerle ilgili olarak bkz. ARTUK, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 29; CENTEL, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 53 vd.

Ancak bütün bu eleştirilerde güvenlik tedbirlerinin münhasıran suç oluşturan fiili işleyen kişi ile ilgili olarak uygulanabileceği düşüncesi hakimdir (Bkz. CENTEL, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 60). Güvenlik tedbirlerinin münhasıran fail hakkında uygulanabileceği yönündeki bu yaklaşım biçiminin doğru olmadığını ifade etmek gerekir.

³²⁸ 1982 Anayasasında “ceza”dan ayrı olarak “ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri” ifadesi kullanılmıştır (m. 38, f. 3). Ancak, güvenlik tedbirlerinin amacı ile cezaya bağlanan hukuki so-

sıra, suçun işlenmesinde kullanılan, suçun konusunu oluşturan eşya, suçtan elde edilen kazanç hakkında bir güvenlik tedbiri olarak müsadereye hükmolunabilmektedir. Ancak, işaret etmek gerekir ki, eşya veya kazanç müsadereye karar verilebilmesi için, cezaya mahkumiyet şart değildir. Yine, mahkeme hükmünde, hapis cezasının ertelenmesi halinde, kişi hakkında denetim süresi içinde denetimli serbestlik tedbirine de karar verilmektedir (m. 51, f. 4, 5). İşaret etmek gerekir ki, ceza ve güvenlik tedbirlerinin niteliğinin birbirinden farklı olması dolayısıyla, işlediği bir suç nedeniyle fail hakkında her iki yaptırıma birden hükmedilmesi, non bis in idem kuralına aykırılık teşkil etmemektedir³²⁹.

Ancak, bazı hallerde, güvenlik tedbiri bir mahkeme hükmüne istinaden değil, bir hakim kararına istinaden uygulanabilmektedir³³⁰.

Hatta, güvenlik tedbiri, örneğin kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyete bağlı kanuni sonuç olarak uygulanmaktadır (m. 53, f. 1). Bu durumda, mahkeme veya hakim tarafından verilmiş bir karara gerek bulunmamaktadır³³¹. Aynı şekilde, koşullu salıverilen hükümlü, hakim veya mahkeme kararına gerek olmaksızın, denetim süresi içinde denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmaktadır (5275 s. İnfaz K, m. 107, f. 7, 8, 9).

TCK'da yer alan güvenlik tedbirleri şunlardır:

- 1) Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırım Olarak Güvenlik Tedbirleri (m. 50).
- 2) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (m. 53).
- 3) Eşya müsadereye (m. 54).
- 4) Kazanç müsadereye (m. 55).
- 5) Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri (m. 56).
- 6) Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri (m. 57).
- 7) Mükerrirlere ve diğer özel tehlikeli suçlulara özgü güvenlik tedbirleri (m. 58; 5275 s. İnfaz K, m. 108).
- 8) Sınır dışı edilme (m. 59).

nuçlar bakımından ve ayrıca, cezaya hükmetmenin yanı sıra güvenlik tedbirinin uygulanabilir olması dolayısıyla, Anayasanın bu ifadesi doğru değildir.

³²⁹ NUHOĞLU, sh. 59/60.

³³⁰ 3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre; çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak, “çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici *tedbir kararı*; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen **çocuk hâkimi tarafından alınabilir.**” (m. 7, f. 1).

³³¹ Bu bakımdan, ceza ve güvenlik tedbirine ancak hakim kararıyla hükmolunabilmesi yönündeki görüşü (ARTUK, M. Emin. Mukayeseli Çocuk Muhakemesi Hukuku, yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul, 1987, sh. 55; NUHOĞLU, sh. 84) sınırlayıcı bulmaktayız.

9) Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri (m. 60).

Diğer kanunlarda da özel güvenlik tedbirlerine yer verilmektedir. Aşağıda, önce TCK'daki güvenlik tedbirlerine ilişkin olarak, daha sonra da diğer kanunlarda düzenlenen güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak açıklamada bulunulacaktır.

XVI. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

I. Toplumda kişiler arasında güven esasına dayalı bir ilişki biçimi hakimdir. Suç işleyen kişi, toplumun kendisine duyduğu güveni bu nedenle yitirmektedir. Bu nedenle, suç işleyen kişi özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Bu yaptırım, yeni TCK'nın "*Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma*" başlıklı 53. maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddede yer alan hükümlere göre, kişinin işlediği suçtan dolayı belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılabilmesi için, işlediği suçun **kasıtlı** bir suç olması ve ayrıca, bu suçtan dolayı, **süresi ne olursa olsun, hapis cezasına mahkum** olması gerekir.

Maddenin birinci fıkrasında, işlediği suç dolayısıyla kişinin hangi haklardan yoksun bırakılacağı sayma yöntemiyle ve sınırlı olarak belirlenmiştir³³².

“Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

*b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,*³³³

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,

yoksun bırakılır.” (m. 53, f. 1)

³³² Bu nedenle, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı **Bankacılık Kanununda** kasten işlediği suç dolayısıyla belli bir süreyle hapis cezasına ya da belirli suçlardan dolayı mahkûmiyetin, banka kurucusu olmaya engel teşkil ettiği hususunda özel hükme yer verilmiştir (m. 8, f. 1, bent d).

³³³ Bu bent hükmüyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermiştir (Anayasa Mahkemesi, 8.10.2015, E. 2014/140, K. 2015/85, RG: 24 Kasım 2015/29542). Bu iptal kararının içeriği ve sonuçlarına ilişkin olarak aşağıda açıklama yapılacaktır.

Söz konusu madde hükümlerine göre, **kasten** işlediği bir suçtan dolayı **hapis cezasına** mahkûm edilen kişi, bu mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hükmün kesinleştiği andan itibaren **cezanın infazı tamamlanıncaya kadar belirli hakları kullanmaktan yasaklanmaktadır** (m. 53, f. 1, 2). Bu kapsamda yasaklanan hakların başında **kamu görevini** üstlenme gelmektedir (m. 53, f. 1, bent a). Bu kamu görevi, Devlet memurluğu gibi **sürekli**, çeşitli kurul üyelikleri gibi **sürelili** ya da belirli bir soruşturma, kovuşturma ve yargılama sürecinde tercümanlık veya bilirkişilik gibi **geçici** olabilir. Bu kamu görevi, Devlet memurluğu gibi **atanma suretiyle**, çeşitli kurul üyelikleri ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan **seçimle** üstlenilmiş olabilir.

II. TCK, m. 53 hükümlerine göre, kişi kasten işlediği bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edildiğinde bu mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hükmün kesinleştiği andan itibaren cezanın infazı tamamlanıncaya kadar seçme hakkı nı kullanmaktan yasaklanmakta idi.

Anayasa Mahkemesi TCK, m. 53, f. 1, bent b’de seçme hakkına getirilen kısıtlamaya ilişkin bu hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.³³⁴

³³⁴ Anayasa Mahkemesi, 8.10.2015, E. 2014/140, K. 2015/85. Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükmü iptal ederken aşağıdaki gerekçelere dayanmıştır:

“Demokratik toplumlarda temel hak ve özgürlükler yönünden serbestlik asıl, sınırlama ise istisnadır. Anayasalar temel hak ve özgürlüklerin hangi nedenlerle ve ne ölçüde sınırlandırılabilirliğini belirlemektedir. Bu anlamda, Anayasa’nın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin kurallara yer verilmiştir.” (pn. 15)

“Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihat hâlini alan kararlarında belirtildiği üzere, her temel hak ve özgürlüğün doğasından kaynaklanan sınırları da bulunmaktadır. Birlikte yaşamın zorunlu sonucu olarak, hak ve özgürlüklerin başkalarının aynı hak ve özgürlüklerden faydalanmasını engelleyici, başkalarına zarar verici mahiyette kullanılmaması gerekir. Ayrıca, Anayasa’nın başka maddelerinde yer alan kuralların da bir diğer temel hak ve hürriyetin sınırını oluşturabilmesi mümkündür.” (pn. 16)

“Anayasa’nın “*Siyasî Haklar ve Ödevler*” başlıklı bölümünde yer alan **seçme hakkı**, yalnızca bir hak olmayıp aynı zamanda bir görev olarak da belirlenmiştir. Bir halk yönetimi olan ve ulusal egemenliği en iyi biçimde yaşama geçiren, çoğulcu, katılımcı, kurallar ve kurumlar düzeni demokrasilerde devlet yönetiminin olmazsa olmaz koşullarından olan seçme hakkı milli iradenin belirlenme aracıdır ve demokrasinin en doğal ve en temel göstergesidir. Seçme hakkı, demokrasiye anlam veren ve onu yaşama geçiren bir haktır. Bu bağlamda vatandaşların en temel haklarından biri olan seçme hakkı, bu hakkın en geniş şekilde kullanılması olanağı ile anlam kazanacağından Anayasa’nın ve ona uygun olarak çıkarılacak yasanın belirleyeceği zorunlu durumlar dışında kısıtlanmaması gerekir.” (pn. 17)

“Demokratik ülkelerde, seçme hakkına sahip olanları ve kimlerin oy kullanabileceğini belirlemeye yönelik tercihlerde bulunma konusunda kanun koyucunun takdir yetkisi bulunmakla birlikte, kanun koyucunun bu yetkisi anayasayla sınırlı olup yapılacak düzenlemelerin, anayasal ilkeler ile temel hak ve hürriyetleri ihlal etmemesi gerekir. Anayasal demokrasinin temelinde, herkesin doğuştan ve insan olması nedeniyle sahip olduğu temel hakların çoğunluğun iradesine rağmen korunması, bu hak ve özgürlüklerin oylama konusu dahi yapılamaması düşüncesi yatmaktadır. Bu anlamda temel hak ve özgürlükler, demokratik siyasi iktidarların

anayasal sınırlarını oluşturmaktadır. Kanunla bu sınırlara uyulup uyulmadığını denetleme görev ve yetkisi de hiç kuşkusuz Anayasa Mahkemesine aittir.” (pn. 18)

“Temel hak ve hürriyetler bakımından meşru amaçla getirilen sınırlamalar Anayasa'nın 13. maddesinde ifade edilen kriterlere aykırı olamaz. Bu anlamda dava konusu kurallar yönünden de kanun koyucunun, Anayasa'nın 67. maddesi uyarınca seçme hakkının kapsamını tespit etme ve düzenleme yetkisi ile ilgili getirdiği düzenlemelerin Anayasa'nın 13. maddesine aykırılık taşıması gerekir.” (pn. 19)

“Temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'da öngörülen sebeplerle ve ancak kanunla sınırlanabilir. Dokunulamayacak “öz”, her temel hak ve özgürlük açısından farklılık göstermekle birlikte kanunla getirilen sınırlamanın hakkın özüne dokunmadığının kabulü için temel hakların kullanılmasını ciddi surette güçleştirip, amacına ulaşmasına engel olmaması ve etkisini ortadan kaldıracı bir nitelik taşıması gerekir.” (pn. 20)

“Temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmaksızın yapılan sınırlamalar yönünden ise bu sınırlamaların, demokratik toplum düzeninin gerekleri ile ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Bir başka deyişle, öze dokunan sınırlamalar, “*demokratik toplum düzeninin gerekleri*” ve “*ölçülülük*” ilkelerine evleviyetle aykırı olacağından, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan sınırlamalar yönünden “*demokratik toplum düzeninin gerekleri*” ve “*ölçülülük*” ilkeleri bakımından ayrıca inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.” (pn. 21)

“Öze dokunma yasağını ihlal etmeyen müdahaleler yönünden gözetilmesi öngörülen “*demokratik toplum düzeninin gerekleri*” kavramı, öncelikle ilgili hak yönünden getirilen sınırlamaların zorunlu ya da istisnai tedbir niteliğinde olmalarını, başvurulabilecek en son çare ya da alınabilecek en son önlem olarak kendilerini göstermelerini gerektirmektedir. “*Demokratik toplum düzeninin gerekleri*”nden olma, bir sınırlamanın demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacıyla yönelik ve ölçülü olmasını ifade etmektedir.” (pn. 22)

“Anayasa'nın 13. maddesinde ifade edilen “*ölçülülük ilkesi*”, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin başvurularda dikkate alınması gereken bir diğer ilkedir. Demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkeleri, iki ayrı kriter olarak düzenlenmiş olmakla birlikte bu iki kriter arasında sıkı bir ilişki vardır. Temel hak ve özgürlüklere yönelik herhangi bir sınırlamanın, demokratik toplum düzeni için gerekli nitelikte, başka bir ifadeyle öngörülen kamu yararı amacını gerçekleştirmekle birlikte, temel haklara en az müdahaleye olanak veren ölçülü bir sınırlama niteliğinde olup olmadığının incelenmesi gerekir.” (pn. 23)

“Ölçülülük, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırma amaçları ile sınırlama araçları arasındaki ilişkiyi yansıtır. Ölçülülük denetimi, ulaşılmak istenen amaçtan yola çıkılarak bu amaca ulaşmak için seçilen aracın denetlenmesidir. Bu sebeple, kuralın hedeflenen amaca ulaşabilmek için elverişli, gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirilmelidir.” (pn. 24)

“Belirtilen nitelikleri gereği, Anayasa'nın 13. maddesinde yer alan ve aralarında sıkı bir ilişki bulunan, “*temel hak ve hürriyetlerin özü*”, “*demokratik toplum düzeninin gerekleri*” ve “*ölçülülük ilkesi*” kavramları, bir bütünün parçaları olup, “*demokratik bir hukuk devleti*”nin özgürlükler rejiminde gözetilmesi gereken temel ölçütleri oluşturmaktadır.” (pn. 25)

“Demokratik toplum, milli iradenin belirlenme aracı olan seçme hakkının en geniş şekilde kullanılabildiği bir düzeni gerektirir. Demokrasilerde devlete düşen görev, bireyin genel, eşit, bireysel, gizli ve serbest seçme hakkını kullanabilme imkânına sahip olmasını sağlamak, özellikle de bu imkânı ortadan kaldırmaya yönelik tutumlardan kaçınmak ve bu yönde gelebilecek olumsuz müdahaleleri engellemektir. Seçme hakkına demokratik toplum düzeni yönünden zorunlu olmadıkça Devletin müdahale etmemesi gerekir. Bu hak meşru amaçlarla sınırlandırılabilir ise de bu sınırlama kişilerin bu hakkını yok edecek veya kullanılamaz hale getirecek şekilde yapılmamalıdır.” (pn. 26)

“Demokrasilerde halkın yasalara bağlılığı olgusunun herkesi kapsayıcı biçimde algılanması ve tanımlanması gerekir. Bunu gerçekleştiren ilke, “*genel oy*” ilkesidir. Genel oy, vatandaşların seçmen olabilme hakkını servet, eğitim, cinsiyet ve ırk bakımlarından sınırlamayan bir se-

çim olgusudur. Genel oy tanımındaki "*genel*" sözcüğü, seçme yeterliliğine sahip olanların oy kullanmalarını anlatır. Seçmen yeterliliği için Anayasa ve yasalarda yer alan koşulların genel oy ilkesini zedelediği, seçmen olabilmek için öngörülen koşulların topluma yarar sağlamak için konulduğu varsayılır." (pn. 27)

"İtiraz konusu kuralla, madde gerekçesinde belirtildiği üzere işlediği suç nedeniyle toplumda kişiye karşı duyulan güvenin sarsılması nedeniyle suçlu kişinin özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olan kişinin seçme hakkını kullanmaktan yoksun bırakılmasının öngörüldüğü kuralın söz konusu amaca ulaşmak için elverişli ve gerekli olduğu söylenebilir." (pn. 28)

"Bununla birlikte ölçülülük ilkesi gereğince, getirilen düzenleme ile ulaşmak istenen amaç arasında makul bir dengenin bulunması gerekmektedir. Orantılılık olarak da ifade edilen ölçülülüğün bu alt ilkesi, amaca ulaşmak için gerekli olan önlemin alınmasına imkân tanımakta, ancak amaca ulaşmak için gerekli olmayan önlemlere başvurulmasına ve ilgili hakkın ölçüsüz bir şekilde sınırlandırılmasına müsaade etmemektedir. Demokratik bir toplumda, temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamanın, bu sınırlamayla güdülen amacın gerektirdiğinden fazla olmaması gerekir. Orantılılık ilkesi, meşru bir amaca ulaşmak için gerekli olan sınırlayıcı araçlardan daha hafif olanı tercih edilebilecekken daha ağır olanına başvurulmasına izin vermez." (pn. 29)

"Seçme hakkına sahip olan bir kimse, bu hakkını oy verme yoluyla açığa vurur. Bu bağlamda seçme hakkının, bu hakkın pratiğe yansıtılması şeklinde ifade edilebilecek olan oy kullanma hakkından ayrı düşünülemeyeceği açıktır. Anayasa'nın 67. maddesinde, vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme hakkına sahip olduğu, seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılacağı, onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılmasının kanunla düzenleneceği ifade edilmiştir. Maddede ayrıca taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oy kullanamayacağı belirtilmektedir. Düzenleme yalnızca kasten işlenen bir suçtan dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oy kullanamayacağını düzenlediğinden **ceza infaz kurumunda bulunmayan hükümlülerin oy kullanmaları bakımından anayasal bir engel bulunmamaktadır.**" (pn. 30)

"İtiraz konusu ibareyle getirilen düzenleme incelendiğinde, **hükümlülerin, ceza infaz kurumunda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kasten işlenen suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin, kişinin seçme hakkından yoksun bırakılmak için yeterli olduğu** anlaşılmaktadır. Kuralla, söz konusu hükümlülerin seçme hakları, **cezanın infazının fiilen ceza infaz kurumunda gerçekleştirildiği süreyi aşacak şekilde sınırlandırılmaktadır.** Bu suretle kuralla seçme hakkına getirilen sınırlama, Anayasa'da seçme hakkının bir tezahürü olarak ifade edilebilen oy kullanma hakkının Anayasa'da açıkça ifade edilen sınırlarını aşmakta, **hükümlünün ceza infaz kurumunda bulunup bulunmadığı dikkate alınmaksızın kategorik bir şekilde kasten işlenen tüm suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûmiyet halinde seçme hakkına sınırlama getirilmektedir.** Kuralla getirilen sınırlama demokratik toplum düzeninde gerekli olmayan ölçüsüz bir sınırlama niteliğinde olduğundan Anayasa'ya aykırıdır." (pn. 31)

"Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu "***hapis cezasına***" ibaresi Kanun'un 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "***seçme*** ve..." ibaresi yönünden **Anayasa'nın 13. ve 67. maddelerine aykırıdır.** İptali gerekir." (pn. 32)

"Anayasa'nın 67. maddesinin beşinci fıkrasında, "***taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar...***" denilerek, yalnızca kasten işledikleri suç nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oy kullanamayacakları ifade edilmiştir. Dolayısıyla ceza infaz kurumunda bulunmayan hükümlülerin oy kullanmalarına anayasal bir engel bulunmamaktadır." (pn. 50)

Anayasa'ya göre, “*taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamaz.*” (m. 67, f. 5)

TCK'nin sistemine göre, **kasten işlediği bir suçtan dolayı bir yıldan daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olan kişi, bu hükmün kesinleşmesiyle cezasını infaz kurumunda çekinceye kadar seçme hakkını kullanamayacaktır** (m. 53, f. 1 [bent b], f. 2). Bu şekilde bir düzenlemeyle, özellikle cezası kesinleşen hükümlünün infazdan kaçmasının önüne geçilmek amaçlanmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi sadece infaz kurumunda kalınan süreyle sınırlı olarak seçme hakkına sınırlama getirilebileceği değerlendirmesiyle bu hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararında, bu değerlendirmelerde bulunulurken, TCK hükümlerine göre, mahkûm olunan ve ertelenmesine hükmedilen hapis cezasının kısa süreli olmasının, yani mahkûm olunan **bir yıl veya daha az süreli hapis cezasının ertelenmesine hükmedilmesi halinde bunun seçme ehliyetine bir etkisinin olmadığı** (m. 53, f. 4) göz ardı edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ile, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kasten öldürme ve çeşitli terör örgütlerinin faaliyeti çerçevesinde ağır suçlar işlemekten dolayı hapis cezasına mahkûm olup da henüz ceza infaz kurumuna girmemiş olan ya da bu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverilen veya **denetimli serbestlik uygulamasıyla salıverilen hükümlülerin oy kullanabilmelerinin yolu açılmıştır.**

III. Anayasa Mahkemesi'nin 2015 yılındaki iptal kararı öncesindeki 53. madde hükümleriyle, **kasten işlediği bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilen kişi,** bu mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hükmün kesinleştiği andan itibaren cezanın infazı tamamlanıncaya kadar **seçilme hakkını kullanmaktan yasaklanmakta idi.**

“Kasten işlediği bir suç nedeniyle mahkûm olduğu hapis cezasının infazının tamamlanıncaya kadar geçecek süre zarfında kişinin seçme hakkını kullanamayacağını öngören itiraz konusu kural, cezanın infazının fiilen ceza infaz kurumunda gerçekleştirildiği süreyi aşacak şekilde sınırlandıran bir düzenleme niteliği taşıdığından, Kanun'un 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “*seçme ve.*” ibaresi yönünden Anayasa'ya aykırıdır.” (pn. 51)

“Öte yandan, Kanun'un 53. maddenin (1) numaralı fıkrasına göre, kişilerin seçilme ehliyetinden yoksun bırakılabilmesi için, mahkûm olunan suçun kasten işlenmiş ve hapis cezasını gerektiren bir suç olması yeterlidir. Kanun'un 49. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre ise süreli hapis cezası kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamayacaktır. Bu durumda kasten işlenen suç nedeniyle hükmedilen bir yıldan daha az süreli hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kişiler seçilme ehliyetinden yoksun bırakılacaktır. Oysa Anayasa'nın, 76. maddesinin ikinci fıkrasında, taksirli suçlar hariç toplam bir yıldan az hapis cezasına mahkûm olma hâli milletvekili seçilmeye engel bir durum olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle kişilerin kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı bir yıldan az hapis cezasına mahkûm olmaları hâlinde dahi seçilme haklarından yoksun bırakılmalarını öngören itiraz konusu kural, Kanun'un 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “*seçilme ehliyetinden.*” ibaresi yönünden Anayasa'ya aykırıdır.” (pn. 52)

Bu düzenlemede, mahkûm olunan hapis cezasının miktarı dikkate alınmamıştı. Önemli olan, kasten işlenen suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyet idi. Bu düzenlemeye göre, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği, muhtarlık seçimlerinde aday olabilmek için, kişinin **kasten işlediği bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması** veya mahkûm edilmişse, bu **cezanın infazının tamamlanmış olması** gerekmekte idi. Bu düzenlemede kasten işlenen suçlar arasında herhangi bir ayırım yapılmamıştır. **Kasten işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan hapis cezasının, süresi ne olursa olsun, infazı tamamlanmış ise, TCK, m. 53 hükümlerinde bu mahkûmiyete bağlanmış herhangi bir hak yoksunluğu bulunmamakta idi.**

TCK, m. 53 hükümleri, kasten işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan hapis cezasının infazı sürecinde İnfaz K, m. 107 hükümlerine istinaden koşullu salıverilme ve İnfaz K, m. 105/A hükümlerine istinaden denetimli serbestlik uygulamasıyla salıverilme halinde de, denetim süresi zarfında cezanın infazı devam ettiği için, **seçilme** ehliyetini ortadan kaldırmakta idi.

Keza, TCK hükümlerine göre, mahkûm olunan hapis cezasının **ertelenmesine hükmedilmiş** de olabilir. Şayet ertelenmesine hükmedilmiş olan hapis cezası **bir yıldan fazla** ise, bu mahkûmiyet de denetim süresi içinde **seçilme** yeterliliğini ortadan kaldırmaktaydı (TCK, m. 53, f. 4).

Anayasa, m. 76, f. 2’ye göre, milletvekili seçilebilmek için, belirli suçlardan dolayı herhangi bir cezaya ve ayrıca, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak gerekir. Milletvekili seçilme ehliyetinin kaybedilebilmesi için, kesinleşmiş mahkûmiyetin varlığı yeterlidir. **Mahkûm olunan cezanın infazı tamamlanmış olsa bile, yasaklılık devam etmektedir.** 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı **Milletvekili Seçimi Kanunu**, m. 11’de de benzer düzenlemeler yer almaktadır. 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı **Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun** kapsamına giren seçimlerde adaylıkla ilgili olarak 2839 s. Kanun, m. 11’e yapılan atfı (m. 9), dikkate almak gerekir³³⁵.

³³⁵ Seçilme yeterliliğine ilişkin koşullar, yukarıda açıklandığı üzere, Anayasanın 76. maddesinde ve 2839 s. Milletvekili Seçimi Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (m. 11). Belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği görevleri ile ilgili seçilme koşulları bakımından bu düzenlemeye atıfta bulunulmuştur (2972 s. Kanun, m. 9, m. 31).

Bu koşullar, adaylık sürecinde denetlenir ve mevcut olduğu tespit edildiğinde adayın başvurusu kesinleşir. Ancak kişinin adaylığı kesinleştikten sonra ortaya çıkan yeni bir sebep dolayısıyla, örneğin verilen mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi halinde, kişi, seçilme yeterliliğine ilişkin koşulları kaybedebilir. Bu durumun **bilahare** ortaya çıkması halinde, kişi belirtilen görevlere seçilmiş olsa bile, kendisine mazbata verilmez; mazbata verilmiş ve göreve başlamış olsa bile, Kanunda belirtilen usule göre görevi sonlandırılır.

Kişinin somut herhangi bir suç işlediği sabit olmaksızın idari bir kararla ve hatta bilahare “kanunlaştırılan” Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinin sonlandırılmış olması, se-

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, TCK, m. 53'te kasten işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanmış ise, bu mahkûmiyete bağlı olarak seçilme ehliyetine sınırlama getirilmemişti. Bu yönü itibarıyla, Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanunu ile TCK, m. 53 düzenlemeleri arasında önemli bir fark bulunmaktaydı. Bu farka rağmen, bu hükümlerin birbirleriyle uyumlu olabilecek ve birbirlerini tamamlayacak şekilde uygulanması mümkündü.

Ancak, Anayasa Mahkemesi, TCK, m. 53, f. 1'de "yer alan *"Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;"* bölümünün, fıkranın (b) bendinde yer alan *"seçilme ehliyetinden"* ibaresi yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE" karar vermiştir³³⁶:

Anayasa Mahkemesi, bu iptal kararını verirken, Anayasa'nın kasten işlediği bir suçtan dolayı mahkûm olduğu hapis cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlüyü **oy kullanmaktan** yasaklayan hükmünü göz ardı etmiştir. Anayasa'ya göre, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç, mahkûm olduğu cezanın süresi ne olursa olsun, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü oy kullanamaz (m. 67, f. 5).

çilme koşullarını ortadan kaldırmaz. **Hukuk dışı** bu **uygulamanın** bugün itibarıyla "kanun"laştırılmış olması, somut herhangi bir suç işledikleri sabit olmadığı sürece bu kişiler bakımından herhangi bir hak yoksunluğu doğurmaz. Nitekim bu mülahazayladır ki, bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbata verilmemesi yönünde karar verilen kişilerin adaylıkları seçim sürecinde kabul edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Seçim süreci henüz başlamadan önce mevcut olan bu durum gerekçe itihaz edilerek seçilen bazı kişilerin göreve başlatılmasının önüne geçilmesinin **hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır**. İşaret etmek gerekir ki, Yüksek Seçim Kurulu, KHK ile ihraç edilmiş olmasına rağmen, pek çok kişinin milletvekili adaylığını kabul etmiş ve seçimi kazandıktan sonra da milletvekili yeterliği için koşulları taşıdığı kabul edilerek, bu görevi ifa etmelerine imkân tanımıştır.

Bu uygulamanın yüksek yargı mensubu "hukukçular" tarafından geliştirilmesinin, Türkiye'de **hakim bağımsızlığı tartışmalarına** gerekçe oluşturacağı kuşkusuzdur.

³³⁶ Anayasa Mahkemesi, 8.10.2015, E. 2014/140, K. 2015/85. Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükmü iptal ederken aşağıdaki gerekçelere dayanmıştır:

"Kanun'un 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasından, kişilerin **seçilme ehliyetinden** yoksun bırakılabilmesi için, mahkûm olunan suçun kasten işlenmiş ve hapis cezasını gerektiren bir suç olmasının yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. Kanun'un 49. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, süreli hapis cezasının kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamayacağı ifade edilmiştir. Bu durumda **kasten işlenen suç nedeniyle hükmedilen bir yıldan az hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde de seçilme ehliyetinden yoksunluk söz konusu olabilecektir**. Oysa Anayasa'nın 76. maddesinin ikinci fıkrasında, belirli suçlardan hüküm giymiş olanların affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmekle birlikte, bu kapsamda yer almayan suçlar yönünden de taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanların milletvekili seçilemeyecekleri kabul edilmiştir. Bir başka deyişle, Anayasa'nın 76. maddesinde sayılan suçlar dışında taksirli suçlar hariç toplam **bir yıldan az hapis cezasına mahkûm olma hâli, milletvekili seçilmeye engel bir durum olarak öngörülmemiştir**." (pn. 7)

"Bu nedenle, kişilerin kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı **bir yıldan az hapis cezasına mahkûm olmaları hâlinde dahi** seçilme haklarından yoksun bırakılmalarını öngören itiraz konusu kural, Kanun'un 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan *"seçilme ehliyeti"* yönünden Anayasa'nın 76. maddesine aykırıdır. İptali gerekir." (pn. 8)

Anayasa Mahkemesinin bu değerlendirmesine göre, kasten işlediği bir suçtan dolayı mahkûm olduğu **bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını çekmek üzere infaz kurumunda bulunan hükümlü, seçilme ehliyetine sahip olabilecek, yani, örneğin milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi seçilebilecek; ancak oy kullanamayacak, seçme hürriyetine sahip olmayacaktır.**

Söz konusu hak yoksunluğu için mahkumiyetin kesinleşmiş olması yeterlidir; ayrıca cezanın infazına başlanmış olması gerekmez. Hatta, TCK, m. 53, f. 2 düzenlemesinden farklı olarak, söz konusu hak yoksunluğu (seçilme ehliyetinin kaybı) kasıtlı suçtan dolayı mahkum olunan hapis cezası infaz edilmiş olsa bile, yani kişi “bihakkın tahliye” edilmiş olsa bile, devam eder^{337, 338}.

³³⁷ Aşağıda açıklayacağımız yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin hükümlerin uygulandığı haller saklıdır.

³³⁸ Ceza mahkumiyetine bağlı hak yoksunluğu sadece TCK’da veya ceza kanunlarında hükme bağlanmış değildir. Belirli bir alana ilişkin olarak düzenleme yapan kanunlarda, belirli bir hak ve yetkinin kullanılabilmesi için belirli suçlardan dolayı veya belirli bir miktar cezaya mahkum olmamak, bir şart olarak aranmaktadır. Örneğin:

1) 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla (m. 25) değiştirilen 28. maddesi şu şekildedir:

“MADDE 28- **Hekimlik mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ... zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak gerekir.**”

Keza, 1219 sayılı Kanunun 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla (m. 29) değiştirilen 45. maddesi şu şekildedir:

“MADDE 45- **Dış hekimliği mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ... zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak gerekir.**”

(Bu iki maddede yer alan “milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar,” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 25.2.2010 t ve E. 2008/17, K. 2010/44 s. Kararı ile iptal edilmiştir: RG: 1 Aralık 2010/27772).

2) 18.12.1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla (m. 167) değiştirilen 4. maddesi şu şekildedir:

“MADDE 4- Aşağıda yazılı haller **eczacılık yapmaya manidir**:

A) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ... zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına **mahkûm olmak.**” (Bu maddede yer alan “milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar,” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 25.2.2010 t ve E. 2008/17, K. 2010/44 s. Kararı ile iptal edilmiştir.).

3) 9.3.1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tazına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla (m. 181) değiştirilen 6. maddesi şu şekildedir:

“MADDE 6- Aşağıda yazılı haller, **veteriner hekimlik mesleğinin icrasına mani teşkil eder:**

a) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ... zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına **mahkûm olmak.**” (Bu maddede yer alan “milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar,” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 25.2.2010 t ve E. 2008/17, K. 2010/44 s. Kararı ile iptal edilmiştir.).

4) 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı **Avukatlık Kanununun** 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla (m. 326) değiştirilen 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi şu şekildedir:

“Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ... zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından **mahkûm olmak,**” **avukat olmaya engel teşkil etmektedir.** (Bu maddede yer alan “milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 25.2.2010 t ve E. 2008/17, K. 2010/44 s. Kararı ile iptal edilmiştir.).

Ayrıca bkz.

1) 24/4/1969 t. ve 1163 s. Kooperatifler Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 338) değiştirilen 56'ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi.

2) 14/9/1972 t. ve 1618 s. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 359) değiştirilen 8'inci maddesinin (b) bendi.

3) 28/7/1981 t. ve 2499 s. Sermaye Piyasası Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 369) değiştirilen 33'üncü maddesinin (f) bendi; keza aynı Kanunun 5728 s. Kanunla (m. 370) değiştirilen 36'ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi.

4) 5/5/1983 t. ve 2821 s. Sendikalar Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 384) değiştirilen 5'inci maddesinin birinci fıkrası.

5) 5/5/1983 t. ve 2822 s. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 387) değiştirilen 56'ncı maddesinin (4) numaralı bendi.

6) 14/10/1983 t. ve 2920 s. Türk Sivil Havacılık Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 430) değiştirilen 18'inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi.

7) 7/6/1985 t. ve 3224 s. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 440) değiştirilen 33'üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi.

8) 28/3/2001 t. ve 4632 s. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 485) değiştirilen 8'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı alt bendi.

9) 18/5/2004 t. ve 5174 s. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 538) ve bilahare 30.7.2008 t. ve 5795 s. Kanunla (m. 2) (RG: 1 Ağustos 2008/26954) değiştirilen 74'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi. Keza aynı Kanunun 5728 s. Kanunla (m. 541) değiştirilen 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi.

10) 10/2/2005 t. ve 5300 s. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 563) değiştirilen 7'nci maddesinin birinci fıkrası.

IV. TCK, m. 53 hükümlerine göre, kişi kasten işlediği bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edildiğinde bu mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hükmün kesinleştiğın andan itibaren cezanın infazı tamamlanıncaya kadar seçme ve seçilme hakkı dışında “*diğer siyasi hakları kullanmaktan*” da yasaklanmakta idi.

Siyasi partiye üye olmak, siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev almak, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Keza, bu hükmün değerlendirilmesinde, 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, m. 11, f. 2 bent b, alt bent 2 ilâ 5 hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Her iki kanun hükümlerinin, birbirleriyle uyumlu olarak ve birbirlerini tamamlayacak şekilde uygulanması mümkün iken; Anayasa Mahkemesi TCK, m. 53, f. 1, bent b’deki kasten işlenen bir suçtan dolayı mahkûm olunan hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hükmün kesinleştiğın andan itibaren cezanın infazı tamamlanıncaya kadar seçme ve seçilme hakkı dışında, **siyasi partiye üye olmak, siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev almak** şeklindeki “*diğer siyasi hakları*” kullanmayı yasaklayan hükmü de Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.³³⁹

11) 7/6/2005 t. ve 5362 s. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 5728 s. Kanunla (m. 573) değiştirilen 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi.

12) 16/6/2005 t. ve 5368 sa. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 5728 s. Kanunla (m. 575) değiştirilen 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi.

³³⁹ Anayasa Mahkemesi, 8.10.2015, E. 2014/140, K. 2015/85.

Anayasa Mahkemesi, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olan kişiyi mahkûm olduğu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar seçme ve seçilme hakkı dışındaki “*diğer siyasi hakları kullanmaktan*” yasaklayan TCK, m. 53 hükmünü iptal kararını aşağıdaki gerekçelere dayandırmıştır:

“Siyasi haklar, devletin kuruluş ve işleyişi ile ilgili temel haklardır. Bu haklar kişiye toplumun temel kural ve yapılarını etkilemek üzere doğrudan hareket etme olanağı tanır, bu nedenle demokrasinin temelini oluştururlar. Kuralla, kişinin, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak seçme ve seçilme hakkının yanı sıra diğer siyasi haklardan da yoksun bırakılacağı belirtilmiş olup söz konusu diğer siyasi hakların, seçme ve seçilme hakları hariç olmak üzere Anayasa’da sayılan siyasi haklar olduğu anlaşılmaktadır.” (pn. 39)

“Siyasi haklar, Anayasa’nın 66 ilâ 74. maddelerinde yer almakta ve Anayasa’nın 66. maddesinde **Türk vatandaşlığı**; 67. maddesinde, **seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları**; 68. maddesinde **siyasi parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma**; 69. maddesinde siyasi partilerin uyacakları esaslar; 70. maddesinde **kamu hizmetine girme hakkı**; 71. maddesinde **mal bildirimi**; 72. maddesinde **vatan hizmeti**; 73. maddesinde **vergi ödevi**; 74. maddesinde ise **dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı** düzenlenmektedir.” (pn. 40)

“Kanun koyucu tarafından gerekçede ifade edildiği gibi suçlu kişinin özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması kabul edilebilir ise de kişinin Anayasa’da belirtilen **tüm siyasi haklardan** yoksun bırakılması sonucunu doğuran kuralın, ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli olduğu söylenemez. Bu nedenle kuralın hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan **ölçülülük ilkesine aykırı** olduğu açıktır.” (pn. 41)

“Açıklanan nedenlerle Kanun’un 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “*ve diğer siyasi hakları kullanmaktan*” ibaresi, Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.” (pn. 42)

TCK, m. 53 hükümlerine göre, kişi, kasten işlemiş bulunduğu bir suçtan dolayı mahkûm olduğu hapis cezasının kesinleştiği andan itibaren infazı tamamlanınca ya kadar **siyasi partiye üye olmak, siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev almak** şeklindeki “*diğer siyasi hakları kullanmaktan*” yasaklanmakta idi³⁴⁰. Bu hükümle güdülen asıl amaç, süresi ne olursa olsun, mahkûm olunan hapis cezasının bir an önce infaz edilmesini sağlamaktır. Yani bu hükümle, kişinin, mahkûm olduğu hapis cezasının infazından kaçarak, örneğin **siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev yapmaya** devam etmesinin önü kapatılmıştı. Bu yasaklama, **cezanın infazı tamamlanınca ya kadar** devam etmekte idi. Buna karşılık, Siyasi Partiler Kanunu hükümleri ise, belirli suçlardan dolayı herhangi bir cezaya ya da kasten işlenen bir suçtan dolayı **beş yıl** veya daha fazla hapis cezasına mahkûm edilmiş olan kişinin, mahkûm olduğu **cezanın infazı tamamlandıktan sonra** da siyasi partiye üye olmasını, siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev almasını yasaklamaktadır.

Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre, m. 11, f. 2, bent b, alt bent 2’de sayılanlar hariç, kasten işlediği herhangi bir suçtan dolayı beş yıldan daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olan kişiler, siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev alabilmekte ve görevde kalmaya devam edebilmektedir. Buna göre örneğin **kasten yaralama** (TCK, m. 86, 87), **işkence** (TCK, m. 94), **uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti** (TCK, m. 188), **uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması** (TCK, m. 190), **uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma** (TCK, m. 191) **suçundan dolayı** sonuç ceza olarak beş yıldan az, dört yıl, dört yıl altı ay **hapis cezasına mahkûm olmuş olan kişi, siyasi partiye üye olabilecek, üye olmaya devam edebilecek, siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev yapabilecektir.**

V- TCK, m. 53, f. 4 düzenlemesine göre, kasten işlediği suçtan dolayı kısa (bir yıl veya daha az) süreli hapis cezasına mahkûmiyet halinde ayrıca bu cezanın ertelenmesine hükmedilmiş ise, bu mahkûmiyete bağlı olarak hükümlü hakkındaki hak yoksunluğu doğmayacaktır. Anayasa Mahkemesi, bu hükmü **seçilme hakkı** yönünden Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir³⁴¹.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’da yer alan vatandaşlık hakkına, vergi yükümlülüğüne, askerlik görevine, dilekçe hakkına ilişkin hükümleri de, TCK, m. 53’deki “siyasi haklar” kavramı içinde değerlendirmeye tabi tutmuştur. Oysa, TCK, m. 53 düzenlemelerinin bu hak ve yükümlülüklerle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yukarıda da açıkladığımız gibi, TCK, m. 53’de yer alan “diğer siyasi haklar” ibaresinden, daraltıcı yorum ilkesinden hareketle, seçme ve seçilme hakkı dışında, **siyasi partiye üye olma, siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev alma hakkını** anlamak gerekir.

³⁴⁰ **Siyasi faaliyette bulunma** bakımından temel ölçüt, **siyasi partiye üye olma**dır. Siyasi partiye üye olamamanın, siyasi parti kurucusu ve yöneticisi olamamayı da ifade ettiği, izahtan varestedir.

³⁴¹ Anayasa Mahkemesi, 8.10.2015, E. 2014/140, K. 2015/85. Bu iptal kararı aşağıdaki gerekçelere dayandırılmıştır:

Türk ceza Kanunu'nun "49. maddesinin (1) numaralı fıkrasında süreli hapis cezasının, Kanun'da aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamayacağı, (2) numaralı fıkrasında da hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezasının, kısa süreli hapis cezası olduğu belirtilmiştir. Hapis cezalarının ertelenmesine ilişkin düzenlemeye ise Kanun'un 51. maddesinde yer verilmiş ve işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezasının ertelenebileceği ifade edilmiştir." (pn. 58)

"Kanun'un 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olan kişinin seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağı kuralı getirildikten sonra, itiraz konusu ibare ile *"kısa süreli hapis cezası ertelenmiş"* olan kişiler hakkında (1) numaralı fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmek suretiyle bu kişilerin seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamaları amaçlanmıştır." (pn. 59)

"Ceza hukukunun toplumun kültür ve uygarlık düzeyi, sosyal ve ekonomik yaşantısıyla ilgili bulunması nedeniyle suç ve suçlulukla mücadele amacıyla ceza ve ceza muhakemesi alanında sistem tercihinde bulunulması Devletin ceza siyaseti ile ilgilidir. Hukuk devletinde, kanun koyucu ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde yetkisini kullanırken, Anayasa'ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, toplumda hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılanacağı, nelerin indirim veya artırım sebebi olarak kabul edilebileceği, hangi cezaların seçenek yaptırımlara çevrilebileceği veya ertelenebileceği ve hangi suçların hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında kalacağı gibi konularda takdir yetkisine sahiptir." (pn. 60)

"Kanun'un 53. maddesinin gerekçesinde, ceza siyasetini belirleme konusunda kanun koyucunun sahip olduğu takdir yetkisine dayanılarak, kişinin işlediği suçun cezasının belli bir ağırlığın üzerinde olmasının, toplumsal güven ilişkisinin önem arz ettiği belli hakların kullanılması bakımından bir yoksunluk hâli olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Bu düşünceden hareketle, kanun koyucu tarafından sahip olunan takdir yetkisi çerçevesinde, ertelenen hapis cezaları arasında bir ayrıma gidilmesinde ve **yalnızca kısa süreli hapis cezalarının ertelenmesi halinde hükümlülerin seçme hakkından yoksun bırakılmamasına yol açan düzenleme getirilmesinde**, bu yönüyle Anayasa'nın 2. maddesinde düzenlenen **hukuk devleti ilkesine aykırılık bulunmamaktadır.**" (pn. 61)

"Öte yandan **işledikleri suç kısa süreli hapis cezasını gerektiren** kişiler ile kısa süreli olmamakla birlikte, iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren kişiler, suçun kamu düzeninde meydana getirdiği tahribatın ağırlığı bakımından aynı konumda bulunmadıklarından, kanun koyucunun bu **kişileri seçme ehliyeti yönünden farklı kurallara tabi kılması, Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.**" (pn. 62)

"Demokrasilerde devlet yönetiminin olmazsa olmaz koşullarından olan seçimlere katılım, seçme hakkının en geniş şekilde kullanılması ile anlam kazanacağından Anayasa'nın ve ona uygun olarak çıkarılacak kanunun belirleyeceği zorunlu durumlar dışında bu hakkın kısıtlanmaması gerekir. Bu bağlamda **kısa süreli hapis cezası ertelenmiş olan kişilerin seçme hakkından yoksun bırakılmamalarında Anayasa'ya aykırı bir yön bulunmamaktadır.**" (pn. 63)

"Anayasa'nın 76. maddesinde milletvekili seçilme yeterliliği düzenlenmiş olup, milletvekili seçilebilme yeterliğine sahip olabilmek için aranan nitelikler arasında, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş olmak, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymemiş olmak koşuluna yer verilmiştir." (pn. 64)

"İtiraz konusu ibare ile **kısa süreli hapis cezası ertelenmiş kişiler, seçilme ehliyetinden yoksun bırakılamayacaktır. Bu bağlamda itiraz konusu ibareyle, ertelenen kısa süreli hapis cezaları bakımından Anayasa'nın 76. maddesinde açık ve ayrıntılı bir şekilde be-**

Anayasa'ya göre kasten işlediği suçtan dolayı **bir yıldan az** süreyle hapis cezasına mahkûm edilmiş olan kişi, bu cezanın ertelenmesine hükmedilmiş olsun veya olmasın, milletvekili seçilme yeterliliğine sahiptir. Ancak, Anayasa, m. 76'da sayılan belirli suçlar dışında kasten işlenen bir suçtan dolayı mahkûm olunan **bir yıl veya daha fazla** süreli hapis cezasının ertelenmesine hükmedilmiş olsa bile, bu mahkûmiyet milletvekili seçilme yeterliliğini ortadan kaldırmaktadır.

TCK, m. 53, f. 4 hükmü, mahkûm olunan kısa süreli ve bu çerçevede **bir yıl** süreli hapis cezasının ertelenmesine hükmedilmiş ise, bu mahkûmiyet milletvekili seçilme yeterliliğini ortadan kaldırmamaktaydı. Bu yönü itibarıyla, söz konusu hüküm, Anayasa'daki milletvekili seçilme hakkının alanını daraltan değil, genişleten bir mahiyet taşımakta idi. Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı üzerine, **kasten işlediği bir suçtan dolayı bir yıl hapis cezasına mahkûm olan kişi, bu cezanın ertelenmesine hükmedilmiş olsa bile, milletvekili seçilme yeterliliğini kaybetmektedir.** Bu durum, **belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi, muhtar ve ihtiyar heyeti üyesi** adayları bakımından da söz konusudur.

VI. TCK, m. 53, f. 1'de söz konusu edilen hak yoksunlukları için **mahkemenin karar vermesine gerek yoktur.** Başka bir ifadeyle, bu hususla ilgili olarak hükümde bir açıklığın bulunması gerekli değildir. Ancak belirtmek gerekir ki, Yargıtay, 765 s. Kanunun uygulanmasının bir yansıması olarak, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca failin mahkûm olduğu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53. maddenin birinci fıkrasında sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da hükmolunması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur³⁴².

VII. TCK, m. 53 düzenlemesinde kasıtlı bir suç işlemek dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyete bağlı hak yoksunluğu süresiz değildir. Mahkûmiyete bağlı hak yoksunluğu, **belli bir süreyle sınırlandırılmıştır.**

Bu sistemde, hak yoksunluğu, **mahkûmiyetin kesinleşmesiyle** başlayıp, mahkûm olunan hapis cezasının **infazı tamamlanıncaya kadar** devam edecektir

lirtilen milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkin düzenleme genişletilmektedir. Oysa 76. maddede yer alan düzenlemenin amacı yasama yetkisini kullanacak kimselerin birtakım nitelikleri taşımasının teminidir. Bu bağlamda milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkin şartların değiştirilmesi ancak Anayasa'da yapılacak bir değişiklikte mümkün olabilir. Dolayısıyla **Anayasa'da yer alan milletvekili seçilme yeterliliği hükümlerinde değişiklik niteliğinde olan itiraz konusu ibare, maddenin (2) numaralı fıkrasında yer alan ".seçilme ehliyetinden." ibaresi yönünden Anayasa'ya aykırıdır.**" (pn. 65)

³⁴² Yargıtay içtihatlarına göre, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına hükmedilmesi halinde, bunun yanı sıra, "TCK'nın 53'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan haklardan koşullu salıverilme tarihine, diğer bentlerde yazılı haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına" hükmedilmektedir. Bkz. CGK, 22.11.2011, E. 2011/9-204, K. 2011/239

(m. 53, f. 2). Ancak bu fıkranın b bendi hükmü, yukarıda açıklandığı üzere, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Bu iptalin seçme ve seçilme ehliyeti bakımından etkileri yukarıda açıklanmıştır.

TCK, m. 53, f. 1 ve 2 düzenlemeleri karşısında, yeni TCK'nın sisteminde, başlangıçta *yasaklanmış hakların geri verilmesinin (memnu hakların iadesinin)* ayrıca düzenlenmesine gerek görülmemiştir.

Nitekim, bu husus, 25.5.2005 tarihli ve 5352 sayılı **Adli Sicil Kanununa**³⁴³ ilişkin Kanun Teklifinin Genel Gerekçesinde açık bir şekilde vurgulanmıştır:

*Yeni TCK'da, "765 sayılı Kanundan farklı olarak, belli bir suçtan mahkumiyete bağlı olarak kişiyi ömür boyu belli haklardan yoksun bırakacak yaptırım sistemi terkedilmiştir."*³⁴⁴

Keza, yeni Adli Sicil Kanununun 10'uncu maddesinin **gerekçesinde** bu hususla ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

"Yeni Türk Ceza Kanununun sisteminde, cezalandırılmakla güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, suça bağlı hak yoksunluklarının da belli bir süreyle sınırlandırılması gerekmiştir. Bu nedenle, bir mahkumiyete bağlı hak yoksunluklarının mahkum olunan cezanın infazı tamamlanuncaya kadar devam etmesi öngörülmüştür.

Ancak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı tamamlandıktan sonra da, bu mahkumiyete ilişkin bilgilerin adli sicil arşiv kaydında yer alması gerekmektedir. Kişinin geçmişine bakılarak cezanın bireyselleştirilmesinin sağlanması ve özellikle tekerrür hükümlerinin uygulanması bakımından bu kayıtların muhafaza edilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Her ne kadar bu sistemde, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazından sonra belli bir suçtan mahkumiyete bağlı hak yoksunluğu kanunla öngörülmüş değilse de; kişinin örneğin belli bir kamu görevine atanması sırasında, adli sicil arşiv kayıtlarının görülmesinde büyük bir yarar bulunmaktadır. Bu bilgiler, atama makamının takdir yetkisinin objektif ölçüler çerçevesinde kullanılmasında önemli bir işlev görecektir.

*Ancak, Anayasanın 76'ncı maddesinde milletvekili seçimi ile ilgili olarak bir sınırlama getirilmiş olduğu için, bu madde uygulamasında Anayasanın söz konusu hükmü saklı tutulmuştur."*³⁴⁵

Bu düşüncelerle; daha önce yürürlüğe girmiş bulunan çeşitli kanunlarda³⁴⁶ yer alan, kasıtlı bir suçtan dolayı belirli süreyle hapis cezasına veya belli suçlardan

³⁴³ RG: 1 Haziran 2005/25832.

³⁴⁴ TBMM Dönem 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 899.

³⁴⁵ TBMM Dönem 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 899.

dolayı bir cezaya mahkum olan kişilerin, bu mahkumiyetleri “**affa uğramış olsalar bile**”, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılması yönünde yeni Adli Sicil Kanununa ilişkin Kanun Teklifi’nde bir hükme yer verilmişti (Teklif metni, m. 19, f. 1, bent b)³⁴⁷.

Ancak, bu hüküm, Teklifin TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında, aşağıdaki gerekçeyle madde metninden çıkarılmıştır³⁴⁸:

“Teklifin 19’uncu maddesi; belli bir suçu işlemekten dolayı verilmiş mahkûmiyet kararına bağlı hak yoksunlukları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde açık bir şekilde düzenlendiğinden, Adli Sicil Kanununda ayrıca bu hususa ilişkin olarak düzenleme yapılması ge-

³⁴⁶ Örneğin, 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı **Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun**un belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliği için aranan şartlarla ilgili olarak 9’uncu maddesinde ve keza, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği için aranan şartlarla ilgili olarak 31’inci maddesinde, 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı **Milletvekili Seçimi Kanununa** (m. 11) atıfta bulunulmuştur.

2839 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin (f) bendine göre;

“**Affa uğramış olsalar bile;**

1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karış-tırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536’ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537’nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.”

milletvekili seçilemezler.

Her ne kadar 2839 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde milletvekili seçilebilmek için aranan şartlar Anayasanın 76’ncı maddesine paralel olarak belirlenmiş ise de; bu şartlar, Anayasal bir gereklilik olmadığı halde, **belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği** için de aranmaktadır.

³⁴⁷ Adli Sicil Kanununa ilişkin Teklifin “Yürürlükten kaldırılan hükümler” başlıklı 19’uncu maddesi şu şekilde idi.

“(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) 22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu,

b) 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu hariç, çeşitli kanunlarda yer alan, belirli suçlardan dolayı mahkum olan kişilerin bu mahkûmiyetleri “affa uğramış olsalar bile” belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin hükümler,

Yürürlükten kaldırılmıştır.”

³⁴⁸ Yapılan değişiklikle kanunlaşan (18’inci) madde metni şu şekildedir:

“(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.”

reksiz görülerek birinci fıkrasının (b) bendi madde metninden çıkarılmış ve 18'inci madde olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir."³⁴⁹.

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, her ne kadar yeni TCK'da kasten işlenen suçlar arasında bir ayırım yapmaksızın ve süre sınırlaması getirmeksizin hapis cezasına mahkumiyet halinde bu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar kişi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmakta ise de; yeni Adli Sicil Kanununa ilişkin Teklifin TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında yeni Adli Sicil Kanununun Geçici 2'nci maddesine yapılan bir ilaveyle; diğer kanunlardaki kasıtlı bir suçtan dolayı belirli süreyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mahkum olan kişilerin, bu mahkumiyetleri "*affa uğramış olsalar bile*", belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin hükümleri saklı tutulmuştur³⁵⁰.

³⁴⁹ TBMM Adalet Komisyonunun 11.5.2005 tarihli ve Esas 2/444, Karar 78 sayılı Raporu (TBMM Dönem 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 899).

³⁵⁰ Söz konusu Geçici 2'nci madde, Adli Sicil Kanununa ilişkin Teklif metninde şu şekilde idi:
"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarı ile bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir, diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76'ncı maddesi hükümleri saklıdır." (birinci fıkra).

"Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76'ncı maddesinde sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için, ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir." (ikinci fıkra). (Bkz. TBMM Dönem 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 899).

Yapılan ilave ile madde metni şu şekli almıştır:

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76'ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır." (birinci fıkra).

"Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76'ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir." (ikinci fıkra).

Bu değişikliğin gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

"Teklifin geçici 2'nci maddesi; çeşitli kanunlarda belli kamu görevlerine atama yapılabilmesi için kişinin belli suçlardan mahkûmiyetinin olup olmadığının araştırılması yönünde özel hükümler bulunma ihtimalinden ve bu hükümleri saklı tutmak amacıyla birinci ve ikinci fıkralarında değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir.": TBMM Adalet Komisyonunun 11.5.2005 tarihli ve Esas 2/444, Karar 78 sayılı Raporu (TBMM Dönem 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 899).

Ancak belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesi, 20.1.2011 tarihli ve E. 2008/44, K. 2011/21 sayılı Kararı ile, söz konusu maddenin birinci fıkrasının "*Anayasanın 76'ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.*" şeklindeki ikinci cümlesini ve ikinci fıkrasında yer alan "*Anaya-*

Bu düşüncenin yansıması olarak, 5411 s. **Bankacılık Kanununda**, “*affa uğramış olsalar bile*”, kasten işlediği suç dolayısıyla belli bir süreyle hapis cezasına ya da belirli suçlardan dolayı mahkum olmanın, banka kurucusu olmaya engel teşkil ettiği hususunda özel hükme yer verilmiştir (m. 8, f. 1, bent d)³⁵¹.

sanın 76'ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için” bölümü, iptal edilmiştir (Karar metni için bkz. RG 14 Nisan 2011/27905). Bu iptal kararı, “**Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe**” girecektir.

³⁵¹ Söz konusu bent metni şu şekildedir:

“Bankaların kurucu ortaklarının;

...

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere **affa uğramış olsalar bile** mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca **üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması** veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın **hapis cezası** gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli **zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştiraktan hükümlü bulunmaması,**

...

Şarttır.”

Bu hüküm, çeşitli yönlerden hatalı bulunmaktadır. Önce affın genel af veya özel af olmasına göre bir ayırım gözetmemesi, söz konusu hükmü hukuki bakımdan illetli kılmıştır. Keza, bent metninde benimsenen sayma yönteminde suçlar özensizce belirlenmiştir. Bu suçlar arasında “yüz kızartıcı” olan ve olmayan ayırımı yapılmıştır. Örneğin zimmet suçu “yüz kızartıcı suç” olarak kabul edilmişken, ihaleye fesat karıştırma bu nitelikte bir suç olarak görülmemiştir.

Bu düzenlemelerin başında Anayasa gelmektedir. Anayasa’nın “milletvekili seçilme yeterliliği”ni düzenleyen 76. maddesine göre;

«... taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla³⁵¹, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.»

Esasında gereksiz olduğunu düşündüğümüz bu hükümler, uygulama açısından da bir kargaşa oluşturacak nitelikte formüle edilmişlerdir.

Fransız hukukuna dayanan “yüz kızartıcı suç” kavramına bu suretle mevzuatımızda pek çok hüküm kapsamında yer verilmiştir. Ancak, dikkat edilmelidir ki, bu kavrama yer verilen kanunlar, esasında maddi ceza hukukuna ilişkin düzenlemeleri içeren kanunlar değildir. İlginçtir ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “yüz kızartıcı suç veya şeref ve haysiyet kırıcı suç” ifadesi kullanılmıştır (m. 48).

Mevzuatta “yüz kızartıcı suç” diye belirlenen suçların da sınırlı olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda birtakım suçlar sayıldıktan sonra, “gibi” ifadesi kullanılarak “yüz kızartıcı suçlar”dan söz edilmektedir.

Aslında bu hükümler, söz konusu affın *genel af* veya *özel af* olmasına göre bir ayırım gözetmemesi nedeniyle, hukuki bakımdan hatalıdır. Anayasada TBMM'nin görev ve yetkileri arasında genel ve özel af sayılmıştır (m. 87). Bu iki af türünün *hukuki sonuçları arasındaki fark*, yeni TCK'nın 65'inci maddesinde açık bir şekilde ifade edilmiştir:

“Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.” (birinci fıkra).

“Özel af ile, hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir.” (ikinci fıkra).

“Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.” (üçüncü fıkra).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacak şartlar bağlamında söz konusu edilen “*yüz kızartıcı suç veya şeref ve haysiyet kırıcı suç*” (m. 48) ibaresiyle ilgili olarak Danıştay'ın kararları arasında birlik bulunmamaktadır. Bir kararında, maddede sayılan suçların sınırlı olduğu kabul edilmiştir (1. Daire, 9.11.1983, 220/260 [Danıştay Dergisi, sayı 54-55, sh. 87]). Buna karşılık, diğer bir kararda ise, bu suçların maddede sayılanlarla sınırlı olmadığı belirtilmiştir (10. Daire, 29.12.1986, 1946/2547 [Danıştay Dergisi, sayı 66-67, sh. 445]).

Bu konuda Danıştay'ın verdiği hukuki mülahazalarla izahı kabil olmayan çok ilginç kararlara da işaret etmek gerekir:

-“Hırsızlık suçundan dolayı TL. ağır para cezasına mahkûm edilen davacının görevine son verilmesinde 657 sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/b maddelerine aykırılık bulunmamaktadır.”: 5. Daire, 22.1.1992, 4323/56 (Danıştay Dergisi, sayı 86, sh. 245).

-“Türk pozitif hukukunda zina fiilini haysiyet ve şeref kırıcı suç olarak kabul etme olanağı bulunma”maktadır: 5. Daire, 13.10.191992, 2846/2603 (Danıştay Dergisi, sayı 87, sh. 283). Yüksek Seçim Kurulu da, zina fiilinin “yüz kızartıcı suç” olmadığı yönünde karar vermiştir: 2.8.1989 tarih ve 1429 sayılı Karar (Yüksek Seçim Kurulu İlke Kararları 1988-1989-1990, sh. 231). Yüksek Seçim Kurulu, *ırza tecavüz suçunun* da “yüz kızartıcı suç” olarak kabul edilemeyeceği yönünde karar vermiştir: 28.6.1997 tarih ve 158 sayılı Karar (Yüksek Seçim Kurulu İlke Kararları 1995-1996-1997, sh. 389).

Yargıtay bir kararında “*yüz kızartıcı suç (ların) kişiyi toplum nazarında küçük düşüren suçlar*” olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Buna göre, *yüz kızartıcı suçlar, ahlâk düzeninin çok şiddetle reddettiği toplumun çok büyük ahlâkî tepkiler gösterdiği suçlardır.*”: CGK, 2.7.1996, 3-144/171 (YKD, Ekim 1996, sh. 1633 vd.).

Aslında suçlar arasında “yüz kızartıcı” olan veya olmayan ayırımı yapılmasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bütün suçlar, esasen *haksızlık* teşkil eden fiillerdir (veya öyle olmalıdır). Dolayısıyla, suç teşkil eden bir fiil işleyen kişi açısından bu durum, yüz kızartıcı bir durum olarak telâkki edilebilir. Bu itibarla, esasen haksızlık ifade eden bir fiille ilgili olarak *suç* nitelendirmesinde bulunulduktan sonra; ayrıca, bununla ilgili olarak “yüz kızartıcı” yakıştırmasında bulunulmasının hukuken izah edilebilir bir tarafı yoktur (Ayrıca bkz: BİLİR, Faruk: *Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona ermesi*, Ankara, 2001, sh. 43 vd.).

Nitekim, Yüksek Seçim Kurulu, bir kararında bu gerçeğe işaret etmiştir: «Ne Türk Ceza Kanunu ne de ceza doktrini, suçları “yüz kızartıcı olanlar” ve “yüz kızartıcı olmayanlar” biçiminde değerlendirmeye ve tasnife tabi tutmuştur.»: 12.2.1985 tarih ve 76 sayılı Karar (Yüksek Seçim Kurulu Kararları, Ankara, 1986, sh. 23/24).

Bu konuya ilişkin olarak ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, dn. 120.

Anayasanın genel af ve özel af ayırımına yer vermesi ve bu iki af türünün hukuki sonuçları arasındaki farkın TCK'da açık bir şekilde ortaya konulması karşısında; yapılan kanuni düzenlemelerle, genel affın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını düşünmekteyiz. Bu itibarla, söz konusu "*affa uğramış olsalar bile*" ibaresini özel affa münhasır kılmak gerekir. Ancak, belirtmek gerekir ki, anlamının bu şekilde daraltılması halinde, söz konusu ibareye kanunlarda yer verilmesinin gereksiz olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Zira bu anlam içeriğiyle söz konusu ibare, malumu ilandan başka bir şey ifade etmemektedir. Aslında bu hükümler, ülkemize özgü yasama faaliyetindeki özensizliğin bir örneğini oluşturmaktadır.

Ancak, belirtmek gerekir ki, çeşitli kanunlardaki bu hükümlere rağmen, 765 s. TCK'nın 121 ila 124 ve 1411 s. CMUK'un 416 ila 420'nci maddelerinde³⁵² düzenlenen **yasaklanmış hakların geri verilmesi** yöntemiyle, hak yoksunluğunu gerektiren suçlardan mahkumiyet halinde de, yasaklanmış olan hakların tekrar kullanılabilmesinin yolu açılabilmekteydi³⁵³.

Fakat TCK'nın 53. maddesi hükümleri karşısında, yeni Türk ceza hukuku mevzuatında başlangıçta yasaklanmış hakların geri verilmesi müessesesine yer verilmesine ihtiyaç duyulmamıştı.

Yeni Türk ceza hukuku mevzuatının hazırlanması sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapmış bulunduğumuz çalışmalar kapsamında bu hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına yönelik girişimlerimizden sonuç alamadığımız için, yeni Türk ceza hukuku mevzuatının kabulünden sonra yürürlüğe giren kanunlarda da benzer hükümlere yer verilmiştir.

³⁵² Yasaklanmış hakların geri verilmesi, önceki mevzuatımızda, koşulları ve sonuçları itibarıyla 765 s. mülga TCK'da ve usulle ilgili hükümler itibarıyla CMUK'da düzenlenmişti. Kurumun menşei, Fransa'dır (GÜNAL, Yılmaz: *Adli Yolla Memnu Hakların İadesi*, Ankara, 1961, sh. 39; ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 317/318).

³⁵³ «İster Türk Ceza Kanunundan ister özel yasadaki kaynaklı, mahkûmiyet neticesi kaybedilen tüm hakların memnu hakların iadesi yoluyla kazanılabileceği, zira bu müessesenin kabul edilmiş amacının mahkûmiyet neticesi kaybedilen kanuni durumu ferde iade etmek olduğu, bu çeşit bir kararla hükümlüye kullanılması menedilen hakları kullanma yetkisi verildiği, mahkûmiyet kararında herhangi bir hak kaybından bahsedilmese dahi, başka yasaların mahkûmiyetin sonucu olarak memuriyete girememe, seçme ve seçilme hakkının kaybı gibi kısıtlamalar getirmesi karşısında, iyi halli olduğunu kanıtlayanlar ve süresinde istemde bulunan hükümlünün memnu haklarının iadesine karar verilmelidir.»: 1.CD, 10.12.1991, 2820/3053 (Savaş/Mollamahmutoğlu I, sh. 1370/1371).

«"Memnu hakların iadesi" ve "genel af" birbirinden farklı müesseseler olup, Anayasamızın 76. maddesindeki ve özel yasaklardaki "affa uğramış olsalar bile" cümlesiyle başlayan suçlar arasında sayıldığı için "süresiz hak mahrumiyeti ve süresiz ehliyetsizlikler" getiren hükümlerin sanık aleyhine etkisinin memnu hakların iadesi yoluyla ortadan kaldırılacağı, esasen hiç bir ehliyetsizlik gerektirmeyen mahkûmiyetlerden dolayı da memnu hakların iadesinin istenebileceği gözönünde tutulmalıdır: 1.CD, 25.11.1992, 2532/2604 (YKD, Mart 1993, sh. 451). Ayrıca bkz GÜNAL, sh. 40, 45; ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 320; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 1035.

Bu bakımdan çeşitli kanunlardaki “*affa uğramış olsalar bile*” ibaresinin yer aldığı hükümlerle, yeni TCK’nın 53. maddesindeki mahkumiyete bağlı hak yoksunluğuna ilişkin hükümleri arasında bir çelişki bulunmaktadır. Eski uygulama alışkanlıklarımızın ve yanlıştaki muhafazakar tutumumuzun sonucu olarak; yeni TCK’nın mahkumiyete bağlı hak yoksunluğuna ilişkin hükümlerine rağmen; çeşitli kanunlarda yer verilen düzenlemelerle, hükmolunan cezanın infazı tamamlanmış ve hatta “*affa uğramış olsalar bile*”, bu mahkumiyete bağlı olarak belirli hakların kullanılabilmesi yasaklanmaktadır³⁵⁴.

³⁵⁴ Süresiz hak yoksunluğu öngörmeyen yeni TCK’ya uyum amacıyla çıkarılan 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde de “**affa uğramış olsa bile**” ibaresine yer verilmiştir. Örneğin:

1) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla (m. 317) değiştirilen 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendi şu şekildedir:

Devlet memurluğuna atanabilmek için,

“Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da **affa uğramış olsa bile** devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından **mahkûm olmamak.**”

Şarttır.

5728 sayılı Kanuna ilişkin 10.4.2006 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-1261/1854 sayılı Tasarıda, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde öngörülen değişiklik metni şu şekilde idi:

“Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı **iki** yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama **ve** kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” (TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 56, sh. 218).

Tasarının TBMM Adalet Komisyonunda müzakereleri sırasında, söz konusu alt bent hükmü, kanunlaşan şekliyle değiştirilmiştir. Bu değişikliğin **gerekçesi** olarak, TBMM Adalet Komisyonunun 28.8.2006 tarihli ve Esas 1/1187, Karar 109 sayılı Raporunda şu açıklamalara yer verilmiştir:

Tasarının, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören (düzenlemesinde [m. 1, f. 73]), memuriyete atanmanın koşullarını belirleyen maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “iki yıl” ibaresi “bir yıl” olarak, “kaçakçılık suçlarından” ibaresinden önce gelen “ve” bağlacı “veya” olarak değiştirilmiştir. Keza, söz konusu alt bende, “devletin güvenliğine karşı suçlar” ibaresinden önce gelmek üzere “**affa uğramış olsalar bile**” ibaresi eklenmiştir. Anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında genel ve özel af çıkarma yetkisi sayılmıştır. Bu iki af türünün hukuki sonuçları arasındaki fark, Türk Ceza Kanununun 65’inci maddesinde ortaya konmuştur. Bu durum karşısında madde metnine eklenen “**affa uğramış olsalar bile**” ibaresini **özel affa özgülemek gerekir.**” (TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 56, sh. 138).

Bu sakıncayı giderebilmek amacıyla 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla, Adli Sicil Kanununa “*Yasaklanmış hakların geri verilmesi*” başlığıyla 13/A maddesi olarak yeni bir madde eklenmiştir (m. 38):

“Yasaklanmış hakların geri verilmesi

MADDE 13/A- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla,

a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması,

2) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla (m. 154) değiştirilen 7. maddesinin yedinci fıkrası şu şekildedir:

“Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan veya bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silâh taşıma ve bulundurma izni verilemez.”

5728 sayılı Kanuna ilişkin 10.4.2006 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-1261/1854 sayılı Tasarıda, 6136 sayılı Kanunun 7. maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen değişiklik metni şu şekilde idi:

“Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, ateşli silâh taşıma ve bulundurma izni verilemez.” (TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 56, sh. 192).

Tasarının TBMM Adalet Komisyonunda müzakereleri sırasında, söz konusu fıkra hükmü, kanunlaşan şekliyle değiştirilmiştir. Bu değişiklikte, fıkra metnine **“affa uğramış olsalar bile”** ibaresi eklenmiştir. Bu değişikliğin gerekçesi olarak, TBMM Adalet Komisyonunun 28.8.2006 tarihli ve Esas 1/1187, Karar 109 sayılı Raporunda şu açıklamalara yer verilmiştir:

*“Anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında genel ve özel af çıkarma yetkisi sayılmıştır. Bu iki af türünün hukuki sonuçları arasındaki fark, Türk Ceza Kanununun 65'inci maddesinde ortaya konmuştur. Bu durum karşısında madde metnine eklenen **“affa uğramış olsalar bile”** ibaresini özel affa özgülemek gerekir.”* (TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 56, sh. 128).

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla (m. 545) değiştirilen 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi şu şekildedir:

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilebilmek için,

*“Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da **affa uğramış olsa bile** devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.”*

Şarttır.

b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması, gerekir.

(2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukuki nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Ancak, bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.

(3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgahının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir.

(4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir.

(5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir.

(6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adli sicil arşivine kaydedilir.

(7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle oluşan bütün masraflar hükümlü tarafından karşılanır.”

Bu maddenin **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir:

“5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesindeki düzenlemeye göre, belli bir suçtan mahkûmiyete bağlı süresiz hak yoksunluğundan söz edilemez. İşlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye karşı duyulan güven sarsıldığı için suçlu kişi, özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Ancak, bu hak yoksunlukları süresiz değildir. Cezalandırılmakla güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, 53'üncü maddede suça bağlı hak yoksunluklarının da belli bir süreyle sınırlandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır. Türk Ceza Kanununda, belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkûmiyetin sonucu olarak ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu söz konusu olmadığı için, yasaklanmış hakların geri verilmesi müessesesine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

Ancak, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunun Geçici 2'nci maddesinde, diğer kanunlardaki kasıtlı bir suçtan dolayı belirli süreyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mahkûm olan kişilerin, belli hakları kullanmaktan süresiz olarak yoksun bırakılmasına ilişkin hükümleri saklı tutulmuştur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki çeşitli kanunlardaki süresiz hak yoksun-

luğu doğuran bu hükümlere rağmen, yasaklanmış hakların geri verilmesi yolunun kapalı tutulması, uygulamada ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki çeşitli kanunlardaki kasıtlı bir suçtan dolayı belirli süreyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mahkum olan kişilerin süresiz olarak kullanılmaktan yasaklandıkları hakları tekrar kullanabilmelerine imkan tanıyan bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.”³⁵⁵

Gerekçede yer alan bu açıklamalar karşısında, ayrıca bir izaha gerek bulunmamaktadır.

VIII. Kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olmakla birlikte,

a) hapis cezası ertelenen,

b) **denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen,**

c) koşullu salıverilen,

hükümlü, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayımlık yetkilerini kullanabilir (TCK, m. 53, f. 3, birinci cümle).

Keza, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olmakla birlikte,

a) hapis cezası ertelenen,

b) **denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen,**

c) koşullu salıverilen,

hükümlünün “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etme”sine izin verilebilir (TCK, m. 53, f. 3, ikinci cümle). Bu izin kararının, maddenin mevcut düzenlemesi karşısında, **hükmü veren mahkemece** mahkumiyet hükmü ile birlikte verilmesi gerekmektedir. Bu kararın, özellikle koşullu salıverilme ve cezanın denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazı bağlamında **infaz hakimi** tarafından verilebilmesine yönelik kanuni düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

IX. İşlenen suç dolayısıyla mahkumiyet halinde, cezanın infazı tamamlandıktan sonra da, belirli bir süre ile sınırlı olarak, belirli hak ve yetkilerin kullanılmasına yönelik yasaklama kararı verilebilmesi hususunda mahkeme yetkili kılınmıştır:

“Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması sure-

³⁵⁵ TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı 5, Sıra Sayısı: 1255, sh. 16 vd.

tiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adli para cezasına mahkûmiyet halinde, hükmünde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adli para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.” (TCK, m. 53, f. 5).

“Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.” (TCK, m. 53, f. 6).

X. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, ergin (reşit) kişi, **“bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm”** olmakla kısıtlanır (m. 407, f. 1) ve mahkum olduğu bu cezanın **infazına başlanmasıyla** bu kişiye vasi tayin edilmesi gerekmektedir (m. 407, f. 2). Bunun için işlenen suçun kasten veya taksirle işlenmiş olmasının önemi yoktur. Önemli olan, **mahkum olunan bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasının infazına başlanmış olmasıdır**. Mahkûm olan kişinin işlerini görecektir durumda olup olmamasının vasi tayini bakımından bir önemi bulunmamaktadır. Bu cezanın infazına başlanmasıyla Cumhuriyet savcısı vesayet makamı olarak sulh hukuk mahkemesinden (4721 s. TMK, m. 397), hükümlüye vasi tayin edilmesini talep eder. Bu talep üzerine hükümlüye vasi tayin edilir. Bu cezanın infazının tamamlanmasıyla, vesayet, mahkemeden bir karar alınmasına gerek olmaksızın, kendiliğinden sona erer (4721 s. TMK, m. 471). Dikkat edilmelidir ki, koşullu salıverilmek (İnfaz Kanunu, m. 107), denetimli serbestlik tedbiri uygulamasıyla salıverilme (İnfaz K, m. 105/A) vesayet ilişkisini sona erdirmemektedir. Zira, infaz devam etmektedir³⁵⁶.

³⁵⁶ Kişi, işlediği suç dolayısıyla mahkum olduğu **bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasının kesinleşmesiyle** “sınırlı ehliyetsiz” sayılmaktadır.

Vesayet altındaki hükümlü, “*ayırt etme gücünü haiz bulunduğu sınırlı da olsa belirli işlemleri yapabilir*”; “*karşılıksız kazandırma amacına yönelik bağışlama, ibra, kefalet alacaklısı olma, işgal ve ihraz yoluyla mülkiyet kazanma gibi işlemleri vasinin iznini almaksızın tek başına yapabilir*”; “*başkalarına devredilemeyen ve hak sahibinin ölümüyle mirasçılara geçmeyen, nişanın bozulması ve manevi tazminat talebi, evliliğin iptali talebi, şikâyet hakkı, kısıtlanmanın kaldırılmasını talep etme hakkı, vasiyet düzenleme gibi kişiye sıkı biçimde bağlı hakları*”, vasinin iznine gerek olmadan kullanabilir. Buna karşılık, “*adın değiştirilmesini ve yaşın düzeltilmesini talep, nişanlanmak, evlenmek, evlat edinme veya edinilme, boşanma davasının açılması gibi bazı kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları içeren işlemler için vasinin rızası veya katılımı aranmaktadır*.”: Anayasa Mahkemesi, 22.3.2023, E. 2022/105, K. 2023/54 (RG: 23 Haziran 2023-32230), pn.10.

“*Öte yandan Kanun’un 462. ve 463. maddeleri uyarınca taşınmazların alımı, satımı, rehin edilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması, ödünç verme ve alma, mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaşılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması gibi işlemlerde vesayet makamının izni; vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi veya evlat edinilmesi, mirasın kabulü, reddi*

Anayasa Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yukarıda içeriği açıklanan 407 ve 471. maddeleri hükümlerini aşağıdaki gerekçe ile Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir³⁵⁷.

“Kural ile özgürlüğü bağlayıcı bir ceza nedeniyle hükümlünün, özellikle şahsi ve mal varlığıyla ilgili bazı hukuki işlemleri yapamayacağından kendisine kanun gereğince mutlak olarak vasi atanmasıyla korunması amaçlanmaktadır. Ancak bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan kişilerin ayırt etme gücünü haiz ve herhangi bir vasi atanmaksızın kendi işlemlerini yürütebilecek durumda oldukları açıktır. Dolayısıyla hükümlü, **kendi işlemlerini görebilecek durumda olup olmadığı değerlendirilmeksizin** kendisine vasi atanmasıyla kural olarak vasinin rızası olmadıkça kendi işlemleriyle borç altına giremeyecek, özellikle mal varlığıyla ilgili kimi işlemlerde vesayet ve denetim makamlarının izni gerekecek, kişiye sıkı sıkıya bağlı **nişanlanma ve evlenme gibi işlemler için dahi öncelikle vasinin rızası aranacak**, kefalet, vakıf kurmak, önemli bağışlarda bulunmak için vasinin onayı olsa da herhangi bir işlem yapamayacaktır. Böylece hükümlünün şahsi gözetimi ve mal varlığının idaresi adına özel hayatın korunması ve mülkiyet haklarına büyük ölçüde sınırlama getirilmektedir.” (pn. 31)

“Bu bağlamda kuralla hükümlünün gerçekten korunmasını gerektiren durumların bulunup bulunmadığının araştırılıp ancak böyle bir durumun varlığı hâlinde vesayet kararı verilmesi hususunda mahkemeye takdir hakkı tanınmamakta ya da ihtiyaçları dikkate alınarak hükümlünün ergin ve ayırt etme gücünün bulunması nedeniyle vesayete göre kişinin ehliyetini daha az sınırlayan ve daha dar koruma sağlayan yasal danışmanlık ve kayımlık atamasına imkân sağlanmamaktadır. Dolayısıyla kuralın ulaşılmak istenen amaç bakımından sınırlamanın zorunlu olmadığını, diğer bir ifadeyle aynı amaca daha hafif bir sınırlama ile ulaşılmışının mümkün olduğunu göstermektedir. Bu nedenle kuralla **hükümlüye zorunlu olarak vasi atanmasının hükümlünün korunması amacı bakımından gerekli olmadığı** sonucuna ulaşılmıştır.” (pn. 32)

İşlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olan kişinin bu cezası seçenek yaptırımlardan birine çevrilmemiş veya ertelenmemiş ise, bu cezanın infazına

veya miras sözleşmesi yapılması gibi işlemlerde denetim makamının izni aranmaktadır. Dolayısıyla vesayet altına alınan hükümlü kendisini borç altına sokan ve mal varlıklarını etkileyen hukuki işlemleri vasinin onayı ya da vesayet makamı ile denetim makamının izni olmadan tek başına yapamaz.”: Anayasa Mahkemesi, 22.3.2023, E. 2022/105, K. 2023/54, pn.12.

“449. madde gereğince de kefalet, vakıf kurmak, önemli bağışlarda bulunmak vasinin onayı olsa da yapılamayan mutlak yasak kapsamındaki işlemlerdir.”: Anayasa Mahkemesi, 22.3.2023, E. 2022/105, K. 2023/54, pn.13.

³⁵⁷ Anayasa Mahkemesi, 22.3.2023, E. 2022/105, K. 2023/54.

kural olarak infaz kurumunda başlanacaktır. Kişinin ceza infaz kurumunda bulunmasının, **mallarını idare, malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma** gibi belirli iş ve işlemleri yapabilme bakımından önemli bir sorun ortaya çıkaracağı kuşkusuzdur. Bu iş ve işlemlerin vekalet yoluyla bir başkasına yaptırılması mümkün olabilir. Ancak, bu iş ve işlemlerin yaptırılabilmesi için bir başkasına **vekalet** vermesi, hükümlü bakımından ilave bir külfet oluşturabilir. Bu nedenle, söz konusu iş ve işlemlerin icrasını gerçekleştirme bakımından, hapis cezasına mahkum olan ve bu cezanın infazı sürecinde ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüye **talepte bulunması halinde vasi tayin edilebilmelidir**. Bu bağlamda vasi tayini için mahkum olunan hapis cezasının süresinin bir önemi bulunmamalıdır. Önemli olan, kişinin mahkum olduğu hapis cezasının infazı sürecinde ceza infaz kurumuna girmesi ve infaz kurumunda bulunmasıdır. Ancak belirtmek gerekir ki, şahsa sıkı sıkıya bağlı olan hakları kullanma bakımından vasi tayinine, vasinin icazetine ihtiyaç olduğunu düşünmemekteyiz.

Tayin edilen vasinin görevinin hükümlünün **ceza infaz kurumunda bulunduğu süre ile sınırlı** tutulması gerektiğini düşünmekteyiz. Şayet reşit ve mümeyyiz olan hükümlü, örneğin koşullu salıverilmeden yararlanarak ceza infaz kurumundan tahliye edilmiş ise, vesayet ilişkisinin sonlandırılması gerekir. Cezanın infazının toplumsal ortamda devam etmesi, hükümlüye vasi tayinini gerektirmemelidir.

Kanaatimizce, bu alanda yapılacak olan düzenlemelerin tutuklular bakımından da uygulanmasını sağlamak gerekir³⁵⁸.

XVII. Eşya Müsaderesi

Yeni TCK'da müsadere³⁵⁹, **eşya müsaderesi** ve **kazanç müsaderesi** olarak ikiye ayrılmıştır³⁶⁰. Bir ceza hukuku yaptırımı olan müsadere, her iki halde de **güvenlik tedbiri** olarak kabul edilmiştir^{361, 362}.

³⁵⁸ <https://izzetozgenc.com/data/contents/ceza-infaz-kurumunda-bulunan-hukumluye-vasi-tayini-sorunu-uzerine.pdf> (Yayına giriş tarihi: 26.6.2023).

³⁵⁹ Müsadere hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Reha Poroy'a Armağan, sh. 319 vd.; ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku(2), sh. 303 vd.; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Yaptırım Teorisi(2), sh. 123 vd.

³⁶⁰ Yeni TCK'na ilişkin Hükümet Tasarısında müsaderenin yanı sıra, "*suç sebebiyle mülkiyetin Devlete geçmesi*" kavramı kullanılmıştır (m. 78). Müsadere kavramının dar yorumlanmasının sonucu olarak, özellikle Alman Ceza Kanunundan etkilenecek ortaya atılmış olan bu kavrama ihtiyaç olmadığı düşüncesiyle; TBMM Adalet Komisyonundaki müzakereler sırasında müsadereye ilişkin hükümler bu ayırım terk edilerek yeniden kaleme alınmıştır. Müsadere konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. YILMAZ, Zekeriya: *Teori ve Uygulamada Müsadere*, Ankara 2003.

³⁶¹ Bir ceza hukuku yaptırımı olan *müsaderenin* hukuki niteliği, 765 s. TCK'nın 36. maddesinin düzenlemesi itibarıyla, Türk ceza hukuku doktrininde tartışılmalı konulardan birini oluşturmaktaydı. Türk Doktrininde, 765 s. TCK'nın 36. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen müsadere, herhangi bir ayırım yapılmaksızın, bir "*ceza*" olarak telâkki edilmektedir: DÖNMEZER/ERMAN II, no. 1556, 1561; İÇEL, Kayıhan: *Kaçakçılıkta Kullanılan Üçüncü Kişilere Ait Taşutların Zorallığı*,

Eşya müsadereisinin konusu, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşya oluşturmaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, işlenen suçun **kasıtlı bir suç** olması gerekmektedir. Bu nedenle, taksirli suçlarda eşya müsadereğine hükmedilemez.

Buna göre, **kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan eşya**³⁶³ müsadere edilebilecektir³⁶⁴. Ancak, madde gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere, müsadereye hükmedebilmek için, “eşyanın iyniyetli üçüncü kişilere ait olmaması gerekir. Başka bir deyişle, kişinin suçun işlenmesine iştirak etmemesi, suçun işlenişinden haberdar olmaması durumunda, sahibi bulunduğu eşya bir suçun işlenmesinde kullanılmış olsa bile, müsadereye hükmedilemeyecektir.” (TCK, m. 54, f. 1)³⁶⁵ Suçun işlenmesinde kullanılan eşya ile suçu işleyen kişiler arasında sıkı bir bağlantı mevcuttur; yani, bu durumdaki müsadere, münhasıran suçun işlenişine iştirak eden kişilerin mülkiyetindeki eşyaya müteallik bulunmaktadır³⁶⁶.

İstanbul ÜHFM 44(1978), sh. 301/302. TCK. Tasarısında aynı şekilde herhangi bir ayırım yapmaksızın, müsadereenin bir “ceza” olduğu kabul edilmiştir (m. 78 gerekçesi). Söz konusu müsadere hükmünün “bir mahkûmiyetin sonucu” olduğu fikri için bkz. YURTCAN, Erdener: *Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Şerhi ve İlgili Mevzuat*, cilt III, İstanbul, 1988, sh. 332; Yargıtay İBK., 5.11.1944, 33/1 (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Ceza-2, 2. bası, Ankara, 1984, sh. 283). Buna karşılık, Yargıtay, oldukça yeni bir Kararında söz konusu fıkradaki müsadereenin, yine herhangi bir ayırım yapmaksızın, bir “tedbir” olduğu kanaatine varmıştır: CGK., 5.7.1982, 3-260/331 İtiraz (ÇAĞLAYAN, Muhtar: *Türk Ceza Kanunu*, C. I, 3. bası, Ankara [tarih yok], sh. 310). Ayrıca, Erem de tatmin edici olmayan bir gerekçeyle müsadereenin genel olarak bir tedbir olduğu görüşündedir: EREM, Genel Hükümler II(12), sh. 384/385.

765 s. TCK’nın 36. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen müsadereenin tedbir olarak kabul edilmesinde doktrin hemfikir iken; Yurtcan, bu fıkradaki müsadereenin de “ceza” olduğu görüşünü dermeyeran etmekte ve gerekçe olarak da, bu durumda bir ceza mahkûmiyetinin bulunmasının aranmamasını (!) göstermektedir (YURTCAN III, sh. 332).

³⁶² Yeni TCK’nın açık hükümlerine rağmen, Türk hukukunda müsadereenin hala bir “ceza” olduğu görüşünü savunan yazarlar vardır: CENTEL, Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, sh. 62; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 9. bası, sh. 325; BAYRAKTAR, Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Genel Bir Değerlendirme ve Genel Hükümler Üzerine Birkaç Eleştiri, sh. 29.

³⁶³ “Instrumenta sceleris”

³⁶⁴ *Suçun işlenişinde kullanılan eşyanın müsadereci cihetine gidilmesi ile, fail üzerinde repressif, zecrî bir etki bırakılması amaçlanmaktadır*: ESER, Schönke Schröder(23), Vorbem. vor § 73, kn. 14, § 74, kn. 1, 18. Aynı şekilde, bir Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında suçun işlenişinde kullanılan eşyanın müsadereisinin “mühim ve kuvvetli bir müeyyide” olduğuna işaret edilmiştir: YİBK. 5.4.1950, 21/7 (YİBK. Ceza-3, 2. bası, Ankara 1984, sh. 481 vd.).

³⁶⁵ Yargıtay, suçun işlenişinde kullanılan eşyanın sanığın nezdinde çalıştığı tüzel kişinin (şirketin) mülkiyetine dahil olması halinde müsadere edilemeyeceğine karar vermiştir: 2. CD. 1.2.1981, 7540/7758 (ÇAĞLAYAN I, sh. 322).

³⁶⁶ Ancak, bazı Kanunlar, eşyanın müsadereci için fiilin işlenişine eşya ile medhaldar olmanın, yani katkıda bulunmanın mutlaka iştirak şeklinde olmasını aramamaktadırlar. Buna göre, eşya sahibinin fiilin işlenişine objektif özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani taksirle medhaldar olması halinde dahi eşya müsadere edilecektir. Meselâ Alman CK., §74a.

Keza, **suçun işlenmesine tahsis edilen eşya** da müsadere edilebilecektir. Örneğin, suç işlemek için kurulmuş bir örgütün işlerinin gördürülmesine tahsis edilmiş olan eşya, müsadere edilebilecektir. Tahsiste bir **devamlılık** özelliği vardır. Suç işlenmesine tahsis edilmiş olan eşyanın müsadere edilebilmesi için, suçun işlenmesinde **kullanılması gerekmektedir**.

Burada söz konusu edilen suçun kasıtlı bir suç olduğunu ve sahibinin iyiniyetli olması durumunda suç işlemeye yönelik bir tahsisin olamayacağını, göz önünde bulundurmak gerekir.

Suçun işlenmesinde kullanılan eşyanın müsadere edilmesi halinde; bu müeyyideyle, fiilin ifade ettiği haksızlık muhtevası arasında makul bir oranın olması gerekir³⁶⁷. Bu nedenle, bazı durumlarda işlenen fiilin haksızlık muhtevasının çok az olması dolayısıyla; bu muhtevayla suçun işlenişinde kullanılan eşyanın müsadere si arasında açık bir oransızlık tezahür edebilir³⁶⁸. Nitekim, söz konusu maddede

Ülkemizde 6831 sayılı Orman Kanununun 108. maddesinin 4. fıkrasına göre, "kaçak orman mallarının taşınmasında kullanılan canlı ve cansız bütün nakil vasıtaları **kime ait olursa olsun** idarece zapt ve mahkemelerce müsaderesine hükmolunur. Anayasa Mahkemesi, iktibas ettiğimiz şu gerekçeyle, söz konusu fıkra hükmünün Anayasa'ya aykırılık iddiasını reddetmiştir: "... doğrudan doğruya suçluluğu veya suçta ortaklığı olmadığı halde, taşıtı üzerinde zoraltım hükmü uygulanan kimse gerçekte kusursuz ve olayla büsbütün ilişkisiz değildir. ... böyle bir kimsenin kusuru, yükümlü olduğu dikkati ve özeni göstererek kendi taşıtıyla yasak eylemin işlenmesine engel olmamaktan doğmakta"dır. Kişi, "taşıtının kaçak orman mallarının taşınmasında kullanılmaması için gereken dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. Bu yükümü yerine getirmeyen taşıt sahibinin, yasak eylem işlendiğinde, kusurlu sayılması ve kusurlu davranışının sonucu olan zoraltım cezasını görmesi gerekir" (30.9.1969, 17/49).

Keza, 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yürürlükten kaldırılan (m. 38) 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı "Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun"un "Kaçak eşya ve madde naklinde **bilerek** kullanılan veya buna teşebbüs edilen her türlü nakil vasıtalarının da müsaderesine hükmolunur" şeklindeki 47. maddesi hükmün Anayasa'ya aykırılık iddiasını Anayasa Mahkemesi yine şu gerekçelerle reddetmiştir: "Maddedeki «bilerek» deyi mi, taşıma aracını kullanan ve idare eden kişinin, bu araçla kaçak eşya taşındığını bilmesi anlamında yorumlanmalıdır. Maddenin, araç sahibinin kaçak eşya taşındığını bilmesi gerektiği yolunda yorumlanmasına yer yoktur". ... "Buradaki sorum, taşıt sahibinin kendi kusuruna dayanmaktadır. Bu kusur, herhangi bir nedenle taşıtını verdiği kişiyi seçerken gereken dikkat ve itina yı göstermemiş olmasından doğmakta"dır. "Buna karşılık, mal sahibinin iradesi dışında kalan (taşıtın zorla elinden alınması veya çalınması gibi) durumlarda taşıtının, kaçak eşya nakline tahsis edilmiş olması yüzünden kendisine bir sorum yükletilemeyeceği ve bu takdirde zor alıma gidilemeyeceği de meydandadır" (14.12.1968, 32/62).

Ayrıca, Yargıtay, 6 yıldan beri ormanda açılıp işletilen tarlayı sürmek için bir başka şahsa talimat verilmesi halinde; bu şahsın, tarlanın söz konusu durumunun bilincinde olup olmadığını araştırmaksızın, tarlayı sürmek için kullandığı traktör ve pulluğun müsaderesini isabetli bulmuştur: CGK. 5.7.1982, 3-260/331 İtiraz (ÇAĞLAYAN I, sh. 310/311). 6831 sayılı Orman Kanununun 108. maddesinin 4. fıkrasına istinaden CGK'nun verdiği 19.3.1979 tarih ve 3-69/132 sayılı Karara ilişkin eleştirel açıklamalar için bkz. İÇEL, İstanbul ÜHFM 44(1978), sh. 297 vd.

³⁶⁷ ESER, Schönke/Schröder(23), § 74, kn. 39.

³⁶⁸ ESER, Schönke/Schröder(23), § 74b, kn. 1 vd.; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF II, sh. 533. Yargıtay, zorla kadın kaçırılmasında kullanılan vasıtanın müsadere edilmesi gerektiğine karar

yer alan hükme göre; “suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suçta nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.” (TCK, m. 54, f. 3)

Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya, suçun icra hareketlerine henüz başlanmamış ise, sadece bu nedenle müsadere edilemeyecektir. Ancak, bu eşyanın niteliği itibarıyla kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda, müsaderesine hükmedilecektir³⁶⁹.

Bu itibarla, suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya, **kamu güvenliği** açısından başlı başına bir **tehlike** oluşturuyorsa, müsadere edilecektir. Örneğin, bir başkasının öldürülmesi için hazır bulundurulmuş patlayıcı madde veya sair bir silah, öldürme suçunun icrasına başlanmış olmasa bile, müsadere edilecektir.

Keza, suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya, **kamu sağlığı** açısından başlı başına bir **tehlike** oluşturuyorsa, müsadere edilecektir. Örneğin, bir başkasını öldürmek için hazır bulundurulmuş zehirli maddenin müsaderesine hükmedilecektir.

Yine, suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya, **genel ahlâk** açısından başlı başına bir **tehlike** oluşturuyorsa, müsadere edilecektir. Örneğin, çocukların görebilmeleri için hazırlanan müstehcen ürünler, müsadere edilecektir.

Dikkat edilmelidir ki, bir başka suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşyanın üretimi, temini veya bulundurulması başlı başına bir suç oluşturabilir. Bu durumda, maddenin dördüncü fıkrasına göre de müsadere kararı verilebilecektir. Zira, dördüncü fıkraya göre, “*üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.*” Ayrıca, söz konusu eşya, *suçun konusunu oluşturan eşya* olması itibarıyla, kazanç müsaderesine ilişkin hükümlere göre de (m. 55) müsadere edilebilecektir.

Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşyanın müsadere edilebilmesi için, sahibinin iyiniyetli olup olmadığını araştırmaya gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, **suçtan meydana gelen eşyanın** müsaderesine hükmedilecektir. Örneğin uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve bu nedenle, tarımının izinsiz olarak yapılması yasak olan bitkilerin yetiştirilmesi durumunda, bunların müsaderesine hükmedilecektir. Ancak, işaret etmek gerekir ki, söz konusu bitkiler, *suçun konusunu oluşturan eşya* olması itibarıyla, kazanç müsaderesine ilişkin hükümlere göre de (m. 55) müsadere edilebilecektir.

vermişken (5. CD, 13.12.1983, 3319/4274 [ÇAĞLAYAN I, sh. 319]); içinde mağdurenin ırzına geçilmesine teşebbüs edilen otonun müsadere edilemeyeceği içtihadında bulunmuştur (5. CD, 31.3.1978, 117/1085 [ÇAĞLAYAN I, sh. 325]).

³⁶⁹ *Hafizoğulları*, yeni TCK’nın, suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşyanın, “*kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda*” müsadere edilmesini amir hükmünün, “*faşizan bir düzenleme*” olduğunu iddia etmektedir: HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 381.

Kazanç müsadereşi gibi eşya müsadereşinin de bir güvenlik tedbiri olarak kabul edilmesi dolayısıyla, müsadereye hükmedilebilmesi için, işlenmiş bir suçun varlığı şarttır. Ancak, bu suç nedeniyle herhangi bir kimsenin cezaya mahkûm edilmesi gerekmemektedir³⁷⁰.

Hatta, belirtmek gerekir ki, yeni TCK'nın sisteminde, *“sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsadereşine hükümlenir.”* (m. 64, f. 1)³⁷¹.

XVIII. Kazanç Müsadereşi

Yeni TCK'nın benimsediği temel düşünceye göre; **suç işlemek bir kazanç kaynağı olarak görülemez ve suçtan elde edilen gelir, kişinin yanında kâr olarak kalmaz.**

Bu nedenle, ekonomik çıkar amacına yönelik olarak işlenen suçlarda suçun işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde edilen gelirin müsadereşi cihetine gidilecektir³⁷².

³⁷⁰ 765 sayılı TCK'nın düzenlemesine göre müsadereye karar verilebilmesi için mahkûmiyet şartı arandığı için; Yargıtay, yaş küçüklüğü dolayısıyla failin cezalandırılmadığı durumlarda *suçun işlenişinde kullanılan eşyanın* müsadere edilemeyeceğine karar vermiştir: 2. CD, 15.9.1981, 5124/5886 (ÇAĞLAYAN I, 325). Ayrıca bkz. 3. CD, 19.3.1969, 4156/4851 (nakleden İÇEL, İstanbul ÜHFM 44[1978], sh. 303, dn. 5; 3. CD, 27.12.1967, 18567/24341 (İÇEL, aynı yer). Ancak, bilahare, suç işleyen kişiye yaşının küçüklüğü nedeniyle ceza tertip edilmese bile, suçta kullanılan bıçağın müsadere edilmesi gerektiği görüşüyle, tam aksine karar vermiştir: CGK, 14.6.1982, 129/279 (MOLLAMAHMUTOĞLU, Sadık/SAVAŞ, Vural: Türk Ceza Kanununun Yorumu, C. II, Ankara, 1987, sh. 552).

Yargıtay, verdiği yeni bir kararda yine eski görüşüne dönmüştür: «TCK'nın 36. maddesi, mahkûmiyet halinde cürüm ve kabahatte kullanılan eşyanın müsadereşini öngördüğü ve sanık hakkında aynı Kanunun 46. maddesi uyarınca ceza tertibine yer olmadığına karar verildiğine (göre) ve suça konu silahın menşeinin de belli olması ve meşru bulunması karşısında; müsadereşine karar verilemeyeceği gözönüne alınarak, silahın, silah sahibinin tespit edilerek mirasçılara iadesi yerine ... müsadereşine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.» 8. CD., 27.2.1997, 1509/2503 (YKD, Temmuz, 1997, sh. 1175). Bu kararın değerlendirmesi hakkında bkz. ÖZGENÇ, Uygulamalı Ceza Hukuku(2), sh. 303 vd.

Suçun işlenişinde kullanılan eşyanın müsadereşi açısından ilginç bir olay şu şekilde cereyan etmiştir: 2813 sayılı Telsiz Kanununa aykırılık dolayısıyla çeşitli özel radyo vericilerinin CMK., mad 86 uyarınca zaptına ilişkin C. Başsavcılığı talebinin reddi üzerine vaki itiraz, *"Tahkikat konusu özel radyo vericileri yönünden müsadereye tabi olan eşya şart ve unsuru nun gerçekleşmediği, diğer bir ifade ile, verilmiş bir mahkûmiyet (kararı) olmadığı gibi, bunların bizzatı suç teşkil eden eşya olarak da kabul edilemeyeceği"* gerekçesiyle, isabetli bulunmamıştır: 7. CD., 4.2.1993, 5364/612 (YKD, Nisan 1993, sh. 625).

³⁷¹ Nitekim, Yargıtay, suçun işlenişinde kullanılan kamyonun sahibinin dava sonuçlanmadan önce ölmesi üzerine kendisi açısından kamu davasının ortadan kaldırılmasına rağmen, kamyonun müsadere edilmesi gerektiğine karar vermiştir: CGK, 13.3.1978, 3-33/80 (ÇAĞLAYAN I, sh. 313/314).

³⁷² Ancak, elde edilen gelirin miktarının belirlenememesi halinde müsadere kararı vermek mümkün olmayacaktır. İşte bu durum göz önünde bulundurularak, ilgili suç tanımlarında hapis cezasının yanı sıra adli para cezası öngörülmüş ve adli para cezasının üst sınırı ayrıca belirlenmiştir.

Yeni TCK'da bir **güvenlik tedbiri** olarak kabul edilen kazanç müsaderezinin konusu, bir “*suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile, bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlar*”³⁷³ oluşturmaktadır (TCK, m. 55, f. 1).

Öncelikle belirtmek gerekir ki, her ne kadar madde metninde açıklık bulunmamakta ise de, işlenen suçun **kasıtlı** bir **suç** olması gerekmektedir.

Buna göre, **suçun işlenmesi ile elde edilen bütün malvarlığı değerleri** müsadere edilebilecektir.

Müsadere edilmesi gereken malvarlığı değerlerinin başında *suçun işlenmesi suretiyle elde edilen maddi menfaatler* gelmektedir.

Suçun işlenmesi *suretiyle* elde edilen maddi menfaate ilişkin tipik örneği, rüşvet suçundan sağlanan menfaat oluşturmaktadır. Suçun işlenmesi suretiyle elde edilen maddi menfaate ilişkin ikinci örneği, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edilen kazanç oluşturmaktadır³⁷⁴.

İşaret etmek gerekir ki, suçun işlenmesi suretiyle elde edilen malvarlığı değerleri, aynı zamanda **suçun konusunu** da oluşturmaktadır. Örneğin, para sahtecilik suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen sahte paralar, suçun konusunu oluşturmaktadır ve bu nedenle müsadereye tabidir.

Suçun işlenmesi suretiyle elde edilen ve suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerlerinin müsadere edilebilmesi için, bunların “*suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.*” Örneğin hırsızlık suçunun konusunu oluşturan veya dolandırıcılık suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen malvarlığı değerlerinin, meşru maliki veya zilyedi belli olduğunda, müsadereye hükmedilmeyip, bu kişilere iade edilmesi gerekmektedir^{375,376}. Ancak, belli bir malvarlığı değerini kişinin

³⁷³ “*scelere quaesta*” ve “*producta sceleris*”

³⁷⁴ Nitekim, Yargıtay, esrar satışından temin edilen paranın müsadere edilmesi gerektiğine karar vermiştir: 5. CD, 25.11.1981, 3018/3455 (ÇAĞLAYAN I, sh. 323).

Yargıtay, genel olarak *suçun işlenmesi suretiyle elde edilen maddi menfaatin* de 765 s TCK'nın 36. maddesinin 1. fıkrasına göre müsadere edilebileceği yönünde içtihatla bulunmuştur: 5. CD, 14.9.1983, 1521/2897 (ÇAĞLAYAN I, sh. 319); 5. CD, 25.5.1982, 1665/1934 (ÇAĞLAYAN I, sh. 320). Hatta, Yargıtay, daha da ileri giderek, fazla fiyatla gazyağı satılması halinde, sadece elde edilen kârın değil; fazla fiyatla satılan gazyağı bedeli ile, mevcut gazyağının birlikte müsadere edilmesi gerektiğine karar vermiştir: 4. CD, 11.11.1980, 6244/6258 (ÇAĞLAYAN I, sh. 323).

³⁷⁵ Hırsızlık suçunda suçun mağdurunun işlenen fiil dolayısıyla çalınan eşyanın aynısını veya bedelini borçlar hukuku hükümlerine göre talep hakkının mevcut olduğu durumlarda müsadere cihetine gidilemez (ESER, Schönke/Schröder[23], § 73, kn. 23).

³⁷⁶ TCK, m. 55, f. 1 “*uyarınca suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsadereye karar verilmesi müm-*

hırsızlık veya dolandırıcılık suçunu işlemek suretiyle elde ettiği muhakkak olmakla birlikte, bunların meşru malik veya zilyedinin belirlenemediği durumlarda, müsadere kararı vermek gerekecektir.

Ayrıca, **suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler** de müsadere edilecektir. Suçun işlenmesi *dolayısıyla* elde edilen malvarlığı değerlerini, suçun işlenmesini teşvik veya suçun işlenmesinden dolayı ödüllendirilmeleri maksadıyla suçu işleyen kişilere sağlanmış olan maddi menfaatler oluşturmaktadır³⁷⁷. Fiilin işlenişinden önce veya sonra, suçun işlenmesi dolayısıyla tedarik edilen maddi menfaatin de müsadere edilmesi gerekir³⁷⁸.

Kazanç müsaderesiyle, suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan maddi menfaatin, kişinin yanında kâr olarak kalmasının önüne geçmek amaçlanmaktadır³⁷⁹.

Müsadere konusu malvarlığı değerinin suç işlenmesi ile veya suçun işlenmesi için doğrudan elde edilen menfaat olması gerekmektedir. “*Bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir.*”

Suçun işlenmesi suretiyle veya suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilen malvarlığı değerlerinin müsadere edilebilmesi için, işlenen fiilin suç oluşturmaya yeterlidir. Fakat, failin bu suç dolayısıyla kusurlu bulunması zorunlu değildir³⁸⁰. Bu haksız kazancın suçun işlenişine iştirak edenler veya üçüncü şahıslar lehine tedarik edilmesi, mü-

kün ise de, anılan madde ve fıkra uyarınca müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekmekte olup; hırsızlık suçunun işlenmesi ile elde edilen para ile satın alınan ... otomobilin hırsızlık suçunun mağduru Ünal Çetintaş'a iade edilmesi gerektiği gözetilmeden müsaderesine karar verilmesi” hukuka aykırıdır: Yargıtay 9.CD, 11.6.2013, E. 2012/3415, K. 2013/9099.

³⁷⁷ ESER, Schönke/Schröder(23), § 73, kn. 8.

³⁷⁸ Yargıtay, bir kararında, suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilen maddi menfaatin 765 s. TCK'nın 36. maddesine göre müsadere edilemeyeceği içtihadında bulunmuştur: Azmettiren tarafından, kaçırma suçunun işlenişine iştirakini temin maksadına matuf olarak, azmettirilene sağlanan para müsadere edilemez. Zira, Yargıtay'a göre, bu durumda ne suçta kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanmış eşya, ne de suçtan husule gelen eşya söz konusudur: CGK, 2.3.1987, 5-464/85 (UYGUN/SAVAŞ/MOLLAHAHMUTOĞLU, Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara, 1987, sh. 6-8).

³⁷⁹ JESCHECK, Lb., 715; ESER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. vor § 73, kn. 18, § 73, kn. 1, 2, 7. Ancak, bu maddi menfaatlere ilişkin müsadere, zararın tazmini maksadına matuf değildir. Bu itibarla, işlenen fiil dolayısıyla meselâ kamu adına meydana gelen zararın tazmini maksadına matuf müeyyideyle, bu fiilin işlenişiyse haksız bir şekilde elde edilen maddi menfaatin müsaderesi birbirlerinden tamamen müstakil olarak tatbik edileceklerdir (Nitekim Yargıtay İBK. 9.1.1946, 35/1 [YİBK. Ceza-2, sh. 593 vd.]).

³⁸⁰ ESER, Schönke/Schröder(23), § 73, kn. 4. Ancak, Yargıtay, yaş küçüklüğü dolayısıyla failin cezalandırılmadığı durumlarda suçun işlenmesi suretiyle elde edilen maddi menfaatlerin müsadere edilemeyeceğine karar vermiştir: 3. CD, 24.12.1980, 904/1979 (ÇAĞLAYAN I, sh. 325).

sadere kararı açısından önemsizdir³⁸¹. Bu üçüncü kişi, bir gerçek kişi olabileceği gibi, bir tüzel kişi de olabilir. Böylece, meselâ sınaî, iktisadî, ticarî faaliyetin icra edildiği tüzel kişilerin organ veya temsilcilerinin suç işlemek suretiyle ilgili tüzel kişi lehine sağladıkları maddi menfaatler de müsadere edileceklerdir (m. 60)³⁸².

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yeni TCK'nın sisteminde, “*sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsadereesine hükümlenir.*” (m. 64, f. 1).

Suçun işlenmesi suretiyle elde edilen ya da suçun konusunu oluşturan eşya bilahare yani suç tamamlandıktan sonra bir başkasının mülkiyetine geçebilir. Eşyayı bu özelliğini bilerek iktisap eden kişinin fiili esasen suç oluşturduğu için, bu durumda kazanç müsadereesine ilişkin hükümlerin işletilmesi bakımından bir sorun söz konusu değildir. Ancak, suçun işlenmesi suretiyle elde edildiğini veya suçun konusunu oluşturduğunu bilmeden Türk Medeni Kanununun koruduğu iyiniyet kuralları (m. 2) çerçevesinde eşyayı iktisap eden kişi bakımından hukuk uygulamamızda bir sorun varlığını halen devam ettirmektedir. Yeni TCK'da kazanç müsadereesiyle bağlantılı olarak da kaim değer müsadereesine ilişkin hükme yer verilmesine rağmen, suçtan elde edilen veya suçun konusunu oluşturan eşyayı suç tamamlandıktan sonra iktisap eden kişinin iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın elindeki eşyaya elkonulmakta ve hatta eşya müsadere edilmektedir. Büyük bir haksızlığa sebebiyet veren bu uygulamanın önüne geçebilmek amacıyla, kitabımızın üçüncü basısında TCK'nın 55. maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki şekilde bir cümle eklenmesinde büyük yarar olduğunu ifade etmiştik³⁸³:

“Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı bilahare iktisap eden kişinin Türk Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamaması gerekir.”

Nitekim, TCK'nın 55. maddesine 26.6.2009 tarihli ve 5918 sayılı Kanunla üçüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra eklenmiştir:

*“Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir.”*³⁸⁴

³⁸¹ ESER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. vor §73, kn. 18; § 73, kn. 14, 34.

³⁸² ESER, Schönke/Schröder(23), §73, kn. 36; aynı şekilde CRAMER, Schönke/Schröder(23), Vorbem. vor §§ 25 ff., kn. 99.

³⁸³ Bkz. üçüncü bası, sh. 685 vd.

³⁸⁴ Bu değişikliğe ilişkin Hükümet Tasarısında söz konusu hüküm,

“Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı bilahare iktisap eden kişinin Türk Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamaması gerekir.”

Söz konusu Kanun Tasarısında bu değişikliğin **gerekçesi** olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Türk Ceza Kanununun ‘Eşya müsadere’ başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasının başında ‘İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla...’ ibaresine açıkça yer verilmiş olmasına karşılık, ‘Kazanç müsadere’ başlıklı 55’inci maddesinin ilk fıkrasında ‘Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.’ hükmüne yer verilmeyle yetinilmiştir. 55’inci maddenin gerekçesinde, ‘Bu hükmün uygulanmasında mağdurun ve iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları korunacak, bunlara ait maddî değerler kazanç müsaderesine tabi tutulmayacaktır.’ denilmiş olmasına rağmen, madde metninde sadece mağdura vurgu yapılmıştır.

Suçun işlenmesi suretiyle elde edilen ya da suçun konusunu oluşturan eşya bilahare yani suç tamamlandıktan sonra bir başkasının mülkiyetine geçebilir. Eşyayı bu özelliğini bilerek iktisap eden kişinin fiili esasen suç oluşturduğu için, bu durumda kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerin işletilmesi bakımından bir sorun söz konusu değildir. Ancak, suçun işlenmesi suretiyle elde edildiğini veya suçun konusunu oluşturduğunu bilmeden Türk Medeni Kanununun koruduğu iyiniyet kuralları (m. 3) çerçevesinde eşyayı iktisap eden kişi bakımından hukuk uygulamamızda bir sorun varlığını halen devam ettirmektedir. 55’inci maddede, kazanç müsadereyle bağlantılı olarak da kaim değer müsadereye ilişkin hükme yer verilmesine rağmen, suçtan elde edilen veya suçun konusunu oluşturan eşyayı suç tamamlandıktan sonra iktisap eden kişinin iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın elindeki eşyaya elkonulmakta ve hatta eşya müsadere edilmektedir. Büyük bir haksızlığa sebebiyet veren bu uygulamanın önüne geçebilmek amacıyla 55’inci madde (ve bir fıkra) eklenmiştir.”^{385, 386}.

şeklinde formüle edilmiş iken; TBMM Adalet Komisyonunda Tasarı metnine yapılan müdahale ile “yararlanamaması” ibaresi doğru olmayan bir şekilde “yararlanamıyor olması” olarak değiştirilmiştir (Bkz. TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 353).

³⁸⁵ TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 353. *Demirbaş*, söz konusu fıkra hükmünün ifade biçimini eleştirmektedir. *Demirbaş*’a göre, söz konusu fıkra hükmü,

“Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için eşyayı sonradan elde eden kişinin bunun bir suç ürünü olduğunu ‘bilerek’ elde etmemiş olması gerekir.”

şeklinde ifade edimesinin daha doğru olacağını düşünmektedir (DEMİRBAŞ, Genel Hükümler, 6. bası, “Altıncı Basiye Önsöz”).

Belirtmemiz gerekir ki, söz konusu fıkra metninde Türk Medeni Kanununu iyiniyet kuralına yapılan atıf, bilinçli ve doğru bir atıftır.

³⁸⁶ **OLAY I:** Bir vakıf üniversitesinin rektör yardımcısı A ile mali işlerini idare eden B, aralarında işbirliği yaparak, üniversiteye ait olan banka hesabındaki bir miktar paranın kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, C’ye ait hesaba aktarılmasını sağlarlar.

Açıklama 1: Vakıf üniversiteleri, kuruluş kanunlarına göre, kamu tüzel kişiliğini haizdir (Bkz. 2809 s. Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, ek madde 3 vd.).

Soru: TCK'nın 6. maddesi hükümlerini de göz önünde bulundurarak, A, B ve C'nin fiillerinin hangi suçu oluşturabileceğini tartışınız ve oluştuğunu düşündüğünüz suçtan dolayı sorumlulukları bakımından her bir suç ortağının iştirak statüsünü belirleyiniz.

Cevap: Vakıf üniversiteleri, kuruluş kanunlarına göre kamu tüzel kişiliğini haiz olduklarına göre, yürüttükleri faaliyetlerin de kamusal bir faaliyet olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. TCK'nın 6. maddesinin birinci fıkrasının c bendinde "*kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi*"lerin kamu görevlisi olduğu belirtilmiştir. Buna göre, **kamusal bir faaliyeti yürüttüklerinden, vakıf üniversitesi çalışanlarının kamu görevlisi sayılmaları gerekmektedir.**

Bu durumda, A, B ve C'nin fiilinin TCK'nın 247. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan **zimmet suçunu** oluşturduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Üniversitenin yönetiminde görev yapan **A ve B**, aralarında işbirliği yaparak üniversitenin mülkiyetindeki parayı zimmete geçirmişlerdir; bu nedenle zimmet suçunun **müşterek faili** olarak sorumlu tutulmaları gerekir.

C'nin iştirak statüsünü vakıf üniversitesinde görevli olup olmamasına göre belirlemek gerekir. C, vakıf üniversitesinde görevli ise, yani **kamu görevlisi ise**, paranın zimmete geçirilmesi fiili üzerinde A ve B ile **müşterek hakimiyet** tesis ettiği için, **müşterek fail** (TCK, m. 37, f. 1) olarak sorumlu tutulması gerekmektedir.

Buna karşılık, C kamu görevlisi değilse, her ne kadar paranın zimmete geçirilmesi fiili üzerinde A ve B ile müşterek hakimiyet tesis etmiş ise de, özel faillik vasfı bulunmadığı için, TCK'nın 40. maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, müşterek fail olarak değil, zimmet suçuna **yardım eden** olarak (TCK, m. 39, f. 1 ve f. 2, bent c) sorumlu tutulması gerekir.

Soru: C'nin hesabına aktarılan para harcandığı için müsadere edilemez. Bu durumda,

- B'nin diğer iki kardeşi E ve F ile iştirak halinde malik olduğu apartman dairesi ile ilgili olarak,
- Yabancı ülkede kurulmuş olan şirketin C'ye ait hisseleri ile ilgili olarak,

müsadere kararı verilebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: **Zimmet suçunun konusunu oluşturan para**, TCK'nın 55. maddesindeki **kazanç müsaderesine** ilişkin hükümlere göre müsadere edilmesi gerekir. Ancak, ilgili vakıf üniversitesine iade edilmesi gerektiği için, bu paranın müsadere edilmemesi gerekir (m. 55, f. 1, ikinci cümle).

Bu para harcanmıştır. Bu nedenle, A, B ve C'nin maliki oldukları sair malvarlığı değerlerinden zimmete geçirdikleri paraya karşılık gelecek kadar miktar, **kaim değer** olarak müsadere edilir (m. 55, f. 2).

B'nin E ve F ile iştirak halinde malik olduğu apartman dairesinden **sadece B'ye tekabül eden pay** müsadere edilebilir. Bunun için önce Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüşmesi gerekir.

Keza, C'nin yabancı bir ülkede kurulmuş olan anonim şirketteki hisseleri de müsadere edilebilir.

Bu şekilde, **faillerin ancak zimmete geçirdikleri paraya karşılık gelecek kadar malvarlığı değerleri** müsadere edilebilir.

Soru: C'nin ortağı olduğu şirket, Türkiye'de bir taahhüt işi üstlenmiştir. Bu taahhüt çerçevesinde söz konusu şirketin Karayolları Genel Müdürlüğünden hakedişlere bağlanmış alacakları mevcuttur. Bu alacaklarla ilgili olarak müsadere kararı verilebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: C'nin işlediği suçtan dolayı, kaim değer olarak bir anonim şirketteki hisseleri müsadere edilebilirse de, bu şirketin malvarlığı değerleri ve alacakları müsadere edilemez.

OLAY II: Bir şebeke tarafından ülkeye kaçak olarak otomobil sokulur ve bunların motor şasi numarası, Türkiye'de trafiğe tescilli olan aynı marka ve fakat eskimiş olduğu için artık kullanılamaz vaziyette bulunan otomobillerden sökülen motor şasi numarası ile değiştirilir. Bu suretle meşru bir yolla elde edilmiş izlenimi uyandırılan otomobiller, motor şasi numarası sökülen otomobillere ait ruhsat bilgileri esas alınarak değişik kişilere satılır.

Soru: TCK'nın belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerini göz önünde bulundurarak, motor şasi numarasında kazıntı, silinti ve sair surette değişiklik yapılmasının, resmi veya özel belgede sahtecilik suçunu oluşturup oluşturmadığını tartışınız.

Cevap: TCK'nın 204'üncü maddesinin gerekçesinde de açıklandığı üzere; belge, eski dilimizdeki "evrak" kelimesi karşılığında kullanılmaktadır ve **yazılı kağıt** anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, **yazılı kağıt niteliğinde olmayan şey**, ispat kuvveti ne olursa olsun, **belge niteliği taşımamaktadır**. Gerekçede ayrıca şu açıklamalara yer verilmiştir:

"Kağıt üzerindeki yazının, anlaşılabilir bir içeriğe sahip olması ve ayrıca, bir irade beyanını ihtiva etmesi gerekir.

Bu yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe edilebilir olması gerekir. Ancak, bu kişilerin gerçekten mevcut kişiler olması gerekmez. Bu itibarla, gerçek veya hayali belli bir kişiye izafe edilemeyen yazılı kağıt, belge niteliği taşımaz. Kağıt üzerindeki yazının belli bir kişiye izafe edilebilmesi için, bu kişinin ad ve soyadının kağıda eksiksiz bir şekilde yazılması ve kağıdın bu kişi tarafından imzalanmış olması şart değildir.

Bir kişinin, düzenlediği belgeye başkasının adını yazması ve belgeyi imzalaması durumunda da bir belge vardır; ancak, bu belge sahtedir. Belge altında adı yazılan ve adına imza konulan kişi, gerçek veya hayali bir kişi olabilir. Bunun, belgenin varlığına bir etkisi bulunmamaktadır.

Bir belgeden söz edebilmek için, kağıt üzerindeki yazının içeriğinin hukukî bir kıymet taşıması, hukukî bir hüküm ifade etmesi, hukukî bir sonuç doğurmaya elverişli olması gerekir.

Ayrıca belirtmelidir ki, her ne kadar, belgeden söz edilen durumlarda yazılı bir kağıdın varlığı gerekli ise de; bazı durumlarda belgenin varlığını kabul için, yazının kağıt üzerinde bulunması gerekmez. Bir metal levha üzerine yazı yazılması hâlinde de belgenin varlığını kabul etmek gerekir. Bu itibarla, araç plakaları da resmi belge olarak kabul edilmek gerekir."

Madde gerekçesinde yer verilen bu açıklamalar karşısında, **otomobilin motor şasi numarasının değiştirilmesi halinde, belgede sahtecilik suçunun oluştuğundan söz edilemez**.

Soru: A, bu özelliğini bildiği otomobili X'ten noterde imzalanan satış sözleşmesiyle satın alır ve gerekli trafik tescil işlemlerini yaptırır. Bu durumda;

a) A'nın fiilleri hangi suçları oluşturur? Açıklayınız.

b) X'in ceza hukuku sorumluluğunu tartışınız.

Açıklama: 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. maddesinin beşinci fıkrasına göre, kaçakçılık suçunun işlenmesine iştirak etmeksizin, kaçak olarak ülkeye sokulmuş olan **"eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, ... kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır."**

Cevap: a) A, otomobili, kaçak olduğunu bilerek satın almıştır. A, kaçak olarak yurda sokulduğunu bilmekle birlikte, bu otomobili ticarî amaçla satın almadığı takdirde, yani sadece kendi kullanımı için satın almış ise, 5607 s. Kanunun 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki suçun oluştuğundan söz edilemez. Çünkü söz konusu suçun oluşabilmesi için, satın alanın **eşyanın kaçak olduğunu bilmesinin (doğrudan kastın)** yanı sıra, bunu **ticarî amaçla** satın alması gerekmektedir. Ancak, bu fiil, A bakımından TCK'nın 165'inci maddesinde tanımlanan **"Suç eşyasını satın alınması veya kabul edilmesi"** suçunu oluşturacaktır. 5607 s. Kanunun 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasında tanımlanan suç ile TCK'nın 165'inci maddesinde tanımlanan suç arasında **genel norm - özel norm ilişkisi** mevcuttur. Somut olayda failin, **özel norm** olarak nitelendirilen **5607 s. Kanunun 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasında tanımlanan suç**a ilişkin hükümlere göre cezalandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, **genel norm** olarak nitelendirilen **TCK'nın 165'inci maddesinde tanımlanan suç**a ilişkin hükümlere göre cezalandırılması gerekir.

b) X, otomobili kaçak olarak yurda sokan suç ortaklarından biridir. Bu nedenle, 5607 s. Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçun işlenmesine iştirakten dolayı **müşterek fail** sıfatıyla cezalandırılması gerekir.

X, kaçak olarak yurda soktukları otomobillerden birini A'ya satmıştır. Kaçak olarak yurda sokulan eşyayı satan kişinin bu suç nedeniyle cezalandırılabilmesi için, eşyanın yurda kaçak olarak sokulması suçuna iştirak etmemiş olması gerekir. **Kişi eşyayı hem kaçak olarak yurda sokan hem de satan ise, bu durumda sadece eşyayı yurda kaçak olarak sokmaktan dolayı 5607 s. Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılacaktır.** Bu eşyayı ayrıca satışı arz etmesini veya satmasını 5607 s. Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasındaki suçtan dolayı verilecek olan cezanın belirlenmesinde dikkate almak gerekir. Bu durum karşısında, **X'i ayrıca 5607 s. Kanunun 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasında tanımlanan kaçak eşyayı satmak suçundan dolayı cezalandırmamız mümkün olmayacaktır.**

Soru: A, satın aldığı otomobilin bu özelliğini, bir süre sonra muayenesini yaptırdığı sırada araç muayene istasyonu görevlilerinin uyarısı üzerine öğrenir. Ancak, başına iş çıkarmamak için herhangi bir işlem yapmaz. Bu durumda;

a) A'nın ceza hukuku sorumluluğunu tartışınız.

b) X'i hangi suçtan dolayı cezalandırmamız gerekir? Açıklayınız.

Cevap: a) Kast suçu oluşturan fiilin işlendiği sırada mevcut olmalıdır. Suçtan elde edilen eşyayı satın alma veya kabul etme fiillerinin icra edildiği sırada eşyanın bu özelliğinin bilinmemesi halinde, bilahare öğrenilmiş olsa bile, satın alma veya kabul etme suçunun oluşmayacağı kuşkusuzdur. Bu mülahazalarla, yeni TCK'nın 166. maddesinde "*Bilgi vermeme*" adıyla yeni bir suç tanımına yer verilmiştir. Buna göre, **satın alma veya bağış gibi bir hukukî ilişkiye dayalı olarak elde edilen eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğinin bilahare öğrenilmesine rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde bulunulmaması**, söz konusu suç oluşturacaktır. Madde gerekçesinde bu çerçevede şu açıklamalara yer verilmiştir:

"Bir hukukî ilişkiye dayalı olarak, örneğin satın alınan veya bağış olarak kabul edilen eşyanın bir suçtan elde edildiğinin daha sonra öğrenilmesi durumunda, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu oluşmaz. Zira, kast, fiilin işlendiği sırada mevcut olmalıdır. Ancak, eşyanın, örneğin satın alındıktan veya bağış olarak kabul edildikten sonra, bir suçun işlenmesi suretiyle veya işlenmesi dolayısıyla elde edildiğinin anlaşılması durumunda; satın alan veya örneğin bağış olarak kabul eden kişi açısından bildirim yükümlülüğü mevcuttur. Bu yükümlülüğe aykırı davranış, madde metninde bağımsız bir suç olarak tanımlanmış bulunmaktadır." (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 572)

Bu suç, bir **gerçek ihmali suç** olarak tanımlanmıştır. Kişinin, satın alma veya bağış gibi bir hukukî ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın veya diğer malvarlığı değerinin bu hukukî ilişki çerçevesinde kendisine devreden kişi veya bir başkası tarafından suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini bilahare öğrenmesi halinde, suçu takibe yetkili makamlara **bildirim yükümlülüğü** doğmaktadır. Bu yükümlülüğün salt yerine getirilmemesi, "*Suç eşyasını satın alınması veya kabul edilmesi suçu*"nu değil, TCK'nın 166. maddesinde tanımlanan suçu oluşturacaktır.

Somut olayda A, satın aldığı otomobilin kaçak olarak yurda sokulduğunu satın aldıktan bir süre sonra muayenesini yaptırdığı sırada araç muayene istasyonu görevlilerinin uyarısı üzerine öğrenir. Ancak, başına iş çıkarmamak için herhangi bir işlem yapmaz.

Bu durum karşısında A'nın fiili ne 5607 s. Kanunun 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasında tanımlanan suçu ne de TCK'nın 165'inci maddesinde tanımlanan suçu oluşturur. A, bu durumda sadece **TCK'nın 166'ncı maddesinde** tanımlanan "**Bilgi vermeme suçu**"ndan dolayı cezalandırılmak gerekir.

b) X yurda kaçak olarak soktukları otomobillerden birini, bu özelliğinden haberi olmayan A'ya satar. A, satın aldığı otomobilin kaçak olarak yurda sokulduğunu bilmemektedir. Bu durumda X'in fiili, TCK'nın 157'nci maddesinde tanımlanan **dolandırıcılık suçu**nu oluşturur.

Soru: A, otomobilin bu özelliğini, ilk defa X ve diğer şebeke mensupları hakkında yapılan soruşturma sürecinde, bu şekilde ithal edilen ve satışı yapılan bütün otomobillere elkonulması üzerine öğrenir. A, satın aldığı otomobilin bu özelliğini bilmediği için hakkında kovuşturmayla yer olmadığı kararı verilir. Ancak, X ve diğer şebeke mensubu kişiler hakkında açılan dava sonucunda A'nın satın aldığı otomobilin de müsadere edilmesine hükümlenir. A, satın aldığı otomobilin müsadere edilmesine ilişkin hükmü, otomobili satın aldığı sırada iyiniyetli olduğunu ve iyiniyetinin korunması gerektiğini ileri sürerek temyiz eder. Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı ise tebliğnamesinde, ruhsatnamede yer alan bilgiler itibarıyla otomobilin 10 yaşında olmasına rağmen, müsadere edilen otomobilin oldukça yeni model lüks bir otomobil olduğu, A'nın bu durumu bilmediği yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği; kaldı ki A otomobilin bu özelliğini bilmese bile, aracın dış görünüşü ile ruhsatnamede yer alan bilgilerin birbirleriyle uyumsuz olduğunu bilmesi gerektiği düşüncesiyle, temyiz talebinin reddi yönünde karar verilmesi mütalaasında bulunur.

Otomobilin müsadere edilmesine ilişkin olarak A'nın savunmasında ve Yargıtay Cumhuriyet başsavcısının tebliğnamesinde ileri sürülen görüşleri değerlendiriniz.

Cevap: Somut olayla bağlantılı olarak sorulan soruya cevap vermeden önce bir hususun açıklığa kavuşturulması gerekir.

Örneğin kaçak orman emvalinden üretilmiş olan mobilyayı bu özelliğini bilmeden satın alan kişinin Türk Medeni Kanununun 2'nci maddesindeki iyiniyet kuralından yararlanması gerekir. Başka bir ifadeyle, kaçak orman emvalinden üretilmiş olduğu bilinmeden satın alınan bu mobilya müsadere edilemez. Ancak, bu mobilyayı satan kişinin satış karşılığında tahsil ettiği paranın müsadere edilmesi gerekir.

Otomobil trafiğe tescil edilmeksizin kullanılamaz yani bu otomobille trafiğe çıkılamaz. Motor şasi numarası değiştirilmiş olan otomobil trafiğe tescil edilemez. Kaçak olarak yurda sokulmuş olan otomobil sahte belge düzenlenmek ve kullanılmak suretiyle trafiğe tescil edilmiş veya ettirilmiş ise, durumun anlaşılması üzerine bu araca ilişkin trafik kayıtlarının ve ruhsatnamenin iptal edilmesi gerekir.

A, otomobili, trafiğe tescil edilmiş ve ruhsata bağlanmış olmasının oluşturduğu güvene dayanarak, X'den noter huzurunda imzalanan sözleşme ile satın almış ve trafikte kendi üzerine tescil ettirmiştir. Bu nedenle, A'nın kaçak eşyayı satın alma suçuna ilişkin kastının varlığından bahsedilemez. Bu durum karşısında A'nın iyiniyetinin Türk Medeni Kanununun 2'nci maddesi hükmü gereğince korunması gerekir. Başka bir ifadeyle, bu durumda A'nın mülkiyetindeki otomobilin müsadere edilememesi gerekir. **A'nın iyiniyetli olarak yani kaçak olduğunu bilmeden satın aldığı otomobil müsadere edilemez ise de, bu otomobile ilişkin trafik kayıtlarının ve ruhsatnamenin iptal edilmesi gerekir. Bu otomobille trafiğe çıkılmasına hiçbir surette izin verilemez.**

Buna karşılık A, bu otomobili satın almanın karşılığında X'e bir miktar para ödemiştir. Bu paranın TCK'nın 55'inci maddesindeki kazanç müsadere edilmesine ilişkin hükümler çerçevesinde müsadere edilmesi gerekir.

Ancak, uygulamamızda, TCK'nın 54 ve 55'inci maddeleri hükümlerine rağmen, otomobil müsadere edilmekte ve fakat bu otomobilin satışı dolayısıyla X'in elde ettiği kazancın müsadere edilmesi yoluma gidilmemektedir.

Kanun hükümlerine rağmen geliştirilmiş bu yanlış uygulamanın, Yargıtay tarafından içtihat oluşturulmak suretiyle önüne geçilmesi gerekir.

Yargıtay Cumhuriyet başsavcısının tebliğnamesinde ileri sürülen görüş hukuken hatalıdır. A'nın satın aldığı otomobilin kaçak olarak yurda sokulduğunu bilmemesi, 5607 s. Kanunun 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasında tanımlanan suça ilişkin kastı ortadan kaldırmaktadır. Söz konusu suç taksirle işlenemez. Taksirle işlenen suçlarda, müsadereye hükmedilemez. Ancak kasten işlenen suçlarda müsadereye hükmedilebilir. Yargıtay Cumhuriyet başsavcısının tebliğnamesi, bu yönden hatalıdır. Tebliğnamede ileri sürülen görüşe göre, A, satın aldığı otomobilin kaçak olarak yurda sokulduğunu

21.3.2007 tarihli ve 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun “Müsadere” başlıklı 13. maddesinde TCK’nın kazanç ve eşya müsadereğine ilişkin hükümlerine atıfta bulunularak bu hükümleri tamamlayıcı mahiyette düzenlemeler yapılmıştır:

“Müsadere

MADDE 13– (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsadereğine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşya taşımada bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir:

a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması.

b) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmada veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.

c) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması.

(2) Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar verilmesi, sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.”

Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesine TBMM Adalet Komisyonunda “bilerek” ibaresi eklenmiştir. Bu ekleme ile ilgili olarak TBMM Adalet Komis-

ve motor şasi numarasının değiştirildiğini bilmeseydi bile, aracın dış görünüşü ile ruhsatnamede yer alan bilgilerin birbirleriyle uyumsuz olduğunu **bilmesiydi gerekirdi**.

Ancak, tebliğnamede ileri sürülen şu değerlendirmeler, dikkate alınmalıdır: “Ruhsatnamede yer alan bilgiler itibarıyla otomobilin 10 yaşında olmasına rağmen, müsadere edilen otomobil oldukça yeni model lüks bir otomobildir ve bu nedenle, A’nın bu durumu bilmediği yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerekir.”

Soru: A’nın satın aldığı otomobilin bu özelliğini, bir süre sonra muayenesini yapan araç muayene istasyonu görevlileri fark ederler. Ancak hiçbir işlem yapmazlar. Bu durumda araç muayene istasyonu görevlilerinin hangi suçtan ve ne sebeple sorumlu tutulması gerektiğini tartışınız.

Açıklama: 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa göre, “Araçların muayeneleri Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından işletme yetki belgesi ile yetki verilmesi halinde ise, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında yapılır. (Hatta) Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini Ulaştırma Bakanlığının onayı ile alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşulu ile devredebilirler.” (m. 35, f. 1)

Cevap: Araç muayene istasyonu görevlileri, bu görevleri bağlamında **kamu görevlisi değildirler**. Bu durumda aracın kaçak olarak yurda sokulduğunu öğrenen araç muayene istasyonu görevlilerinin TCK’nın 278’inci maddesinde tanımlanan “**Suçtu bildirmeme**” suçunu işlediğini kabul etmek gerekir.

yonunun 5.12.2006 tarihli ve Esas: (1/1240), (2/403), (2/644), Karar: 114 sayılı Raporunda şu açıklamalara yer verilmiştir: “*Aslında, Türk Ceza Kanununun eşya müsadereesine ilişkin 54'üncü maddesi hükümleri karşısında böyle bir ilaveye gerek bulunmamaktadır. Ancak, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun müsadereye ilişkin 36'ncı maddesindeki hükümlerin yetersiz olması dolayısıyla, (bu Kanun) ile yürürlükten kaldırıl(an 10.7.2003 tarihli ve) 4926 sayılı (Kaçakçılıkla Mücadele) Kanunun(un) 20'nci maddesinde bu ibareye yer verilen düzenleme yapılmıştı. Söz konusu ibarenin metinden çıkarılmasının uygulamada tekrar eskiye dönüş yapıldığı hususunda tereddüt doğurabileceği düşüncesiyle, fıkra metnine bu ekleme yapılmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki gereksiz olmakla birlikte, yapılan ekleme ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 54'üncü maddesindeki hükümler arasında bir çelişki oluşmuş değildir.*”³⁸⁷, ³⁸⁸, ³⁸⁹.

³⁸⁷ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1275, sh. 15 vd. Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sh. 58.

³⁸⁸ **Anayasa Mahkemesinin 17.12.2015** tarihli ve 2013/3044 bireysel başvuru sayılı kararına (RG: 3 Şubat 2016/29613) konu teşkil eden olayda; yurt dışından alınarak 17.2.2000 tarihinde yurda sokulan otomobil, 18.2.2000 tarihli müracaat formuna istinaden trafik tescil müdürlüğü tarafından MÖ adına tescil edilir. Söz konusu otomobil MÖ tarafından 24.11.2000 tarihinde noter satış senedi ile BY'ye satılır. 27.11.2000 tarihinde de araç, trafik siciline BY adına tescil edilir ve buna göre araçla ilgili olarak trafik tescil belgesi (ruhsatname) düzenlenir.

Bilahare söz konusu otomobile elkonularak, aralarında MÖ ve BY'nin de bulunduğu çeşitli kişiler hakkında kaçakçılık suçu işledikleri iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma yapılır. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme BY'nin beraatine ve otomobil üzerindeki elkoyma kararını kaldırarak BY'ye iadesine hükmeder (Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 15.2.2006, E. 2003/116, K. 2006/51). Ancak, Yargıtay, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda söz konusu hükmü bozar (7.CD, 31.3.2010, E. 2007/13802, K. 2010/5535).

Bu arada söz konusu otomobilin Türkiye'ye ithali ve trafiğe tescili sürecinde resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi dolayısıyla açılan davada mahkeme, aralarında BY'nin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında mahkumiyet kararı vermiş (Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, E. 2009/227, K. 2009/256) ve bu karar kesinleşmiştir.

Kaçakçılık suçundan dolayı açılan davada bozma kararına uyan mahkeme, dava zamanaşımının dolması nedeniyle düşme kararı vermiştir. Ancak mahkeme, bu düşme kararına rağmen, suç işlemek suretiyle elde edilmiş ve suç konusu eşya olması sebebiyle, 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 13. maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince otomobilin müsadereesine hükmetmiştir (Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 16.9.2010, E. 2010/439, K. 2010/657). Söz konusu hüküm, Yargıtay tarafından yapılan temyiz incelemesi sonucunda onanarak kesinleşmiştir (7.CD, 29.11.2012, E. 2012/3094, K. 2012/29937).

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında belirtildiği üzere; trafik sicili, devlet eliyle resen tutulan, motorlu araçların teknik ve fiziki özellikleri ile üzerlerinde yer alan, başta mülkiyet hakkı olmak üzere aynı hakları ve çeşitli kısıtlamaları gösteren resmi bir kayıt sistemidir (kn. 46).

Trafik sicili ve bu sicile dayanılarak düzenlenen araç tescil belgesi (ruhsatname), belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Trafik sicili, içerdiği hususların doğruluğuna ilişkin karine teşkil eder (kn. 48).

Trafik siciline tescilli araçlarda, noterde yapılan satış veya devir işleminin sonrasında aracın zilyetliği alıcıya devredildiğinde, mülkiyeti de geçmiş olacaktır (kn. 49). Bu itibarla, trafik sicilindeki tescil kurucu değil, açıklayıcı nitelik taşımaktadır (kn. 50).

Mevzuata uygun bir şekilde gümrük işlemleri yapılmaksızın ve vergileri ödenmeksizin yurda kaçak olarak sokulan ve herhangi bir şekilde trafiğe tescil edilen otomobili bilahare satın alan kişinin iyiniyetli olup olmadığı bir sübut sorunudur ve her somut olayın şartları itibarıyla belirlenmelidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, somut olay bağlamında belgede sahtecilik suçu ile ilgili olarak açılan davada mahkeme, diğer suç ortakları ile birlikte BY hakkında da resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı mahkumiyet hükmü tesis etmiştir (kn. 73). Bu kabul karşısında, BY'nin iyiniyetli olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bu itibarla, söz konusu otomobille ilgili olarak müsadereye hükmedilmesi hukuka uygundur.

Ancak, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında, yurda kaçak olarak sokulan ve buna rağmen herhangi bir şekilde trafik siciline tescil edilen otomobilin, bilahare, bu sicil kayıtlarının doğruluğuna inanarak, iyiniyetli bir kişi veya kişiler tarafından satın alınması halinde de, müsadere edilebileceği yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Herhangi bir surette ithal işlemine tabi tutulup ithal ve trafiğe tescil edildikten sonra, devlet eliyle tutulan trafik sicil kayıtlarının doğruluğuna güvenerek bu aracı usulüne göre satın alan kişinin iyiniyetli olduğunda kuşku bulunmamaktadır. TCK'nın müsadereye ilişkin hükümleri, Türk Medeni Kanununun iyiniyete ilişkin 3. maddesi hükmüne atıfda bulunarak, iyiniyetle iktisap edilmiş olan bu menkul mal üzerindeki mülkiyeti korumaktadır. Suçun işlenmesi suretiyle elde edilen ve dolayısıyla, suçun konusunu oluşturan eşyayı bilahare örneğin satın almak suretiyle iktisap eden kişinin Türk Medeni Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanması halinde, bu eşyanın müsadere edilmemesi gerekir.

Oysa Anayasa Mahkemesi bu durumda da aracın müsadere edilebileceğini, ancak bilahare aracı iyiniyetle satın alan kişinin idare mahkemesinde tam yargı davası açarak, müsadere sebebiyle uğradığı zararı devletten tazmin edebileceği yönündeki Danıştay kararlarına atıfda bulunarak, bu kararların doğruluğunu kabul etmiş bulunmaktadır:

“Yurda giriş yaptıktan sonra trafik tescil işlemleri yapılan ve bu şekilde üçüncü kişilere satılan taşıtların yurda giriş işlemlerinin veya trafik tescil işlemlerinin gerçeği yansıtmadığının sonradan anlaşılması halinde bu araçların trafikten men edilerek el konulmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Ancak, bir aracın trafiğe çıkabilmesi için yasal işlemlerin tümünün tamamlanmış olması, söz konusu araçların başkalarına satış ve devrine herhangi bir engel bulunmaması durumunda, bu araçları satın ve devir alan iyiniyetli üçüncü kişilerin sahibi bulundukları araçlara sonradan el konulması halinde uğradıkları zararların hizmet kusuru ilkesi uyarınca ilgili idarelerden tazmini gerekmektedir.” (Danıştay Onuncu Dairesi, 16.12.2009, E. 2007/62, K. 2009/10528).

“Uyuşmazlıkta, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, kendisine yetkili makamlar tarafından sunulan belgelere istinaden kayıt ve tescil işlemleri yapmasında hizmet kusuru bulunmasa bile Emniyet Genel Müdürlüğü'nce usulüne uygun olarak tescil işlemleri yapılan aracı satın alan kişinin bu kayıtlar nedeniyle uğradığı zararın kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca tazmin edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, gümrük idaresinin, araç ithalatı sırasında kullanılan belgelerin gerçeğe uygun olup olmadığına inceleme ve denetleme yetkisi bulunduğundan, bu inceleme ve araştırma nedeniyle hizmet kusuru işlediğinden söz edilemeyeceği açık olmakla birlikte, ithaline müsaade ettiği aracı satın alan davacının, olayda herhangi bir kusurunun bulunmaması ve aracın ithali ile ilgili işlemlerde bir ilgisinin tespit edilememesi karşısında uğradığı zararın kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca tazmin edilmesi gerekmektedir.” (Danıştay Onuncu Dairesi, 8.5.2007, E. 2005/1011, K. 2007/2423).

Danıştay'ın söz konusu kararlarını dikkate alan Anayasa Mahkemesine göre, hukuk sistemimizde, kaçak olarak yurda sokulan eşyanın bu sebeple müsadere edilmesi halinde, iyiniyetli malik yönünden “müsadere nedeniyle uğranılan zararın tazminine dair etkin bir tazminat yolu” bulunmaktadır (kn. 78). Oysa Danıştay'ın söz konusu kararları hukuka aykırıdır. Şayet verilmiş olan müsadere hükmü hukuka uygun ise, burada bir hizmet kusurundan bahsetmek

mümkün değildir. Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı da, TCK'nın müsadereye ilişkin hükümleri göz ardı edilerek verilmiştir. Kararda TCK'nın 55. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden hiç bahsedilmemesi, dikkat çekicidir.

Söz konusu araç, üretilmesi, bulundurulması ve dolayısıyla, ülkeye ithali yasak olan eşya değildir; aksine, yasak olmayan eşya olup, gümrük işlemleri usulüne göre yaptırılmadan ve dolayısıyla gerekli vergiler tam olarak ödenmeksizin ülkeye ithal edilen araçtır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararında, bu ayırım gözetilmeksizin, söz konusu araç, “ithali yasak eşya” olarak kabul edilmiştir (kn. 65).

Mahkeme kararlarında, ülkeye kaçak olarak ithal edilmesine rağmen trafik siciline tescil edilen aracı sicil kayıtlarının doğruluğuna güvenerek iyiniyetle satın alıp mülkiyetini iktisap eden kişinin, satın alma bedeli olarak ödediği para ile ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bunun sebebini, iyiniyetle satın alan kişinin ödediği paranın tazmini amacıyla aracı satın aldığı kişi aleyhine özel hukuk hükümlerine göre dava açma hakkının olması oluşturmaktadır. Ancak, bu hakkın varlığına rağmen, çoğu zaman, aracı iyiniyetle satın alan kişinin, satın alma bedeli olarak ödediği parayı tazmin edemediği bir gerçektir. Bu sebeptendir ki, kaçakçılık ve belgede sahtecilik suçlarını işleyen kişilerin, bu suçları işlemek suretiyle ithal ettiği ve trafik siciline kaydedilmesini sağladığı aracı satarak elde ettiği ziyade kazanç, yanlarında kâr olarak kalmaktadır. Oysa TCK'da, kaim değer mäsaderesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir (m. 54, f. 2; m. 55, f. 2). Buna göre, müsadere edilebilecek eşyanın herhangi bir şekilde tüketilmesi veya elden çıkarılması halinde, bu eşyanın değeri kadar paranın suç ortaklarından müştereken ve müteselsilen tahsiline yönelik olarak, kaim değer mäsaderesine hükmedilmelidir.

³⁸⁹ Anayasa Mahkemesinin 29.9.2016 tarihli ve 2014/8060 bireysel başvuru sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; SB, sevk ve idaresindeki minibüs ile yolda seyrederken, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde aracın kontrolünü kaybeder ve orta refüje çıkan aracın tekerleri patlar. Bu kaza üzerine, minibüste Afganistan, Burma ve Pakistan uyruklu 41 kaçak göçmen bulunduğu anlaşılar.

Bu olay dolayısıyla SB ile, Diyarbakır trafik sicilinde aracın adına kayıtlı olduğu başvuru ve diğer üç kişi hakkında göçmen kaçakçılığı suçunu (TCK, m. 79, f. 1, bent a) işledikleri iddiasıyla kamu davası açılır.

İlk derece mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, SB ve diğer üç sanığın göçmen kaçakçılığı suçunu işlediklerini kabul ederek, her biri hakkında hapis ve adli para cezasına, başvurunun ise “*atılı suça iştirak ettiğine dair herhangi bir bilginin olmadığı*” gerekçesiyle **bera**atine hükmetmiştir. Keza, mahkeme, göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde “*kullanılan ve suç tarihinde aracı sanık A'ya haricen sattığını söylediği için tescil maliki*” (başvurucu) **iyiniyetli kabul edilemeye**(rek.) 21 ... *plaka sayılı aracın müsadere*sine karar” vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki gerekçelerle, söz konusu müsadere hükmüyle başvuru bakımından bir hak ihlalinin gerçekleşmediği yönünde karar vermiştir:

“... **trafik sicilindeki tescil kurucu değil açıklayıcı niteliktedir.**” (Paragraf no. 55)

Söz konusu “*araç, trafik sicilinde başvuru adına tescillidir. Dolayısıyla bu trafik sicil kayıtları, 4721 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile 2918 sayılı Kanun'un 20. maddesi hükümleri uyarınca aracın mülkiyetinin başvurucuya ait olduğuna ilişkin karine oluşturmaktadır. Ancak başvuru ceza soruşturması sırasında verdiği ifadesinde, bu aracı 29.000 TL bedelle A'ya noter satışı olmadan ve yazılı bir sözleşme de yapılmadan satarak devrettiğini beyan etmiş, kovuşturma sırasında da bu ifadesini yinelemiş, "Araç üzerime kayıtlı olduğu için aracı karakoldan almaya gitmiştim"* şeklinde beyanda bulunmuştur. A da soruşturma ve kovuşturma sırasında verdiği tutarlı ifadeleriyle bu aracı başvurucudan sözlü anlaşma ile satın aldığını, borcunu tamamen ödemediği için devrini henüz almadığını, bu aracı yolcu taşımacılığı işinde kullandığını ve aracın şoförü olarak da SB'yi görevlendirdiğini beyan etmiştir. Araç sürücüsü SB ise başvurunun akrabası olduğunu, başvuru adına kayıtlı aracın iki buçuk ay önce A tarafından satın alındığını ve bu minibüsle yolcu taşımacılığı yaptığını, kendisinin de aracın şoförü olduğunu ifade etmiştir. Bü

dan A'ya satıldığı , A'nın bu aracı yolcu taşımacılığı işinde kullandığı ve araç şoförü olarak da başvurusunun akrabası SB'yi görevlendirdiği anlaşılmaktadır.” (Paragraf no. 56)

“Buna göre başvuru konusu olayda göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı gerekçesiyle müsadereesine karar verilen minibüs, trafik sicilinde başvuru adına tescilli olup olay tarihinden önce başvuru tarafından bir başka kişiye satılmakla birlikte bu aracın ceza davasına konu olaydan önce yasanın öngörülen noterde satış yöntemi kullanılmadan (haricen) sözlü bir anlaşma ile satıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Yargıtay içtihatlarına göre taraflar arasındaki harici satış sözleşmesi 2918 sayılı Kanun'un 20. maddesinin (d) bendi gereğince resmi şekilde düzenlenmediği için geçersizdir.” (Paragraf no. 57)

“Somut olayda trafik sicilinde başvuru adına kayıtlı araç, yasanın öngördüğü resmi bir şekilde satılmamış olduğundan bu aracın satışına ilişkin olarak yapılan harici satış sözleşmesi hukuken geçersiz olup bu nedenle **aracın mülkiyeti** de anılan mevzuat hükümlerine göre **henüz satın alan kişiye geçmemiştir**.” (Paragraf no. 58)

“... somut olay bakımından aracın trafik sicilinde kayıtlı maliki olan başvurusunun -resmi şekilde sözleşme yapılmamış olduğundan- aracın mülkiyetini henüz devretmemiş olduğu, aracı haricen satın alan kişinin ise anılan mevzuat hükümlerine göre "işleten" olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.” (Paragraf no. 60)

“Müsadere ile temel olarak mülkün suç için kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Başvuru konusu olayda da başvurusunun aracı, somut olayda "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında göçmenlerin yasa dışı olarak taşınmasında yani "suç için nakil vasıtası" olarak kullanıldığı gerekçesiyle müsadere edilmiştir. Mahkeme, atılı "göçmen kaçakçılığı" suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunmadığından **başvurusunun beraatine** karar vermiştir. Dolayısıyla başvuru ile müsadere kararının ilgili olduğu suç arasında doğrudan bir illiyet bağı olmadığı belirlenmiştir. Ancak araç trafik sicilinde başvuru adına kayıtlı olmakla birlikte bizzat başvurusunun beyanına göre bu suçun işlenmesinden birkaç ay önce haricen bir başka kişiye satılmıştır. ... Yargıtay içtihatlarına göre yasanın öngördüğü şekilde resmi sözleşme yapılmadığı için bu harici satış sözleşmesi geçerli değildir. Bununla birlikte aracı haricen satın alan A, bu aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işletip araç üzerinde fiili tasarrufla bulunduğundan 2918 sayılı Kanun'un 3. maddesine göre "işleten" sıfatını haizdir. Mahkeme, aracı işleten A ile araç sürücüsü SB hakkında ise "göçmen kaçakçılığına teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle mahkumiyete karar vermiştir.” (Paragraf no. 91)

“Buna göre başvuru, aracını herhangi bir suç için bizzat kullanmış değilse de bu aracını haricen bir başka kişiye satarak rızasıyla bu kişiye teslim etmiş; böylelikle söz konusu aracın kullanımı ve işletilmesine ilişkin tasarrufu aracı devrettiği kişiye bırakmıştır. Anayasa'nın 35. maddesinin üçüncü fıkrasında, mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı olarak kullanılamayacağı açık olarak hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aracın satışına ilişkin parasal edimin yerine getirilmediği gerekçesiyle yasanın öngördüğü resmi şekilde satış sözleşmesi yapmayan başvuru, kimi durumlarda bu aracın işletilmesi ve kullanılması nedeniyle doğan sonuçlara da katlanmak durumunda kalabileceğini **öngörmelidir**. Diğer bir deyişle trafik sicilinde kayıtlı aracını yasanın öngördüğü resmi şekilde sözleşme yapmak suretiyle devretmeyen **başvurusunun**, bu aracın suçta kullanılması nedeniyle müsadere yol açan olay bakımından aracın bir suçta kullanılmaması için en azından üzerine düşen **özen yükümlülüğünü yerine getirmede** söylenebilir. Nitekim Mahkeme, bu aracın işleteni ve araç sürücüsü hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan mahkumiyet hükmü vermiş ve aracın da bu suçta kullanıldığını tespit ederek müsadere karar vermiştir.” (Paragraf no. 92)

“Öte yandan başvurusunun geçersiz satış sözleşmesi nedeniyle borçlar hukuku kuralları çerçevesinde aracı haricen sattığı kişiye karşı genel hükümlere göre dava açabilme olanağı da bulunmaktadır.” (Paragraf no. 93)

“Açıklanan nedenlerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan **mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine** karar verilmesi gerekir.” (Paragraf no. 95)

Müsadere kararının ne suretle infaz edileceği önem taşımaktadır. Müsaderesine karar verilen malvarlığı değerinin, eşyanın cinsine göre infaz sureti bakımından farklı bir yol ve yöntem izlenmektedir³⁹⁰.

Ekskurs 3. Şirket Malvarlığının Müsaderesi

Bir şirketin bünyesinde icra edilen ticari faaliyetlerden elde edilen gelir, **bir terör örgütüne, bu örgütün bünyesinde işlenen suçların icrası sürecinde ihtiyaç duyulan maddi imkanların sağlanması amacıyla, bu örgütün suç faaliyeti çerçevesindeki harcamalarında kullanılmak üzere tahsis** edilebilir. Bir tahsisin söz konusu olduğu durumlarda, **tahsis** edilen malvarlığının suçun işlenmesinde kullanılmış olması gerekmemektedir. Terör örgütünün, tahsis edilen malvarlığı değeri üzerinde fiili olarak tasarruf imkanının bulunması yeterlidir. Bu durumda, tahsis konusu malvarlığı değerlerinin, şirket karının ve hatta, tahsisin mahiyetine göre, şirkete ait bilumum malvarlığı değerlerinin müsaderesine hükmedilebilir. **Suç işlemeye tahsis edilmiş olan malvarlığı değerlerinin** müsaderesine hükmedilebilmesi için, tahsis konusu malvarlığı değerlerinin suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilmiş olması gerekmemektedir. Burada önemli olan, malvarlığı değerlerinin, şirketin, şirkete ait karın, **suç işlemek amacına tahsis** edilmiş olmasıdır. Bu durumda şirketin bütün malvarlığının müsaderesine hükmedilebilmesi için, şirket ortağı olan kişilerin bu şirketin, şirket kazancının, şirketin maddi imkanlarının terör örgütüne tahsis edilmiş olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Yani bu durumda tahsis olgusuna ilişkin olarak şirket ortaklarının kastının varlığını araştırmak gerekir.

Kısaca belirtmek gerekir ki, söz konusu karar, Anayasa Mahkemesinin **17.12.2015** tarihli ve 2013/3044 bireysel başvuru sayılı kararında (RG: 3 Şubat 2016/29613) varılan sonuç ile çelişmektedir. 2013/3044 bireysel başvuru sayılı karara konu teşkil eden olayda aracın müsadere edilmesinin hukuka aykırı olmamasına rağmen, Anayasa Mahkemesi tutarsız gerekçelerle hak ihlali kararı vermiştir (Söz konusu Karara ilişkin hukuki değerlendirmeler için bkz. bir önceki dipnot). İnceleme konumuz olan olayda ise, ilk derece mahkemesinin kararındaki çelişkiye rağmen, Anayasa Mahkemesi müsadereye hükmedilmesiyle mülkiyet hakkının ihlal edilmediği sonucuna varmıştır.

Keza, bu karar, Anayasa Mahkemesinin **20.9.2017** tarihli ve 2014/14195 bireysel başvuru sayılı kararında (RG: 25 Ekim 2017/30221) yapılan değerlendirmeler ve varılan sonuç ile de çelişmektedir.

Söz konusu karara konu teşkil eden olayda, başvuru finansal kiracı sıfatıyla temin ettiği otobüsü, ortağı olduğu limited şirkete kiralar. Bu şirketin faaliyeti çerçevesinde Bulgaristan’la Türkiye arasında yolcu taşımacılığında kullanılan **otobüsün içinde kaçakçılık suçunun gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve gizlemek için özel bir bölme oluşturulur**. Bulgaristan’dan Türkiye’ye yolcu taşımada kullanıldığı sırada otobüsteki bu **bölme** içinde **507.350 AVRO** ve **80.000 USD** nakit para ile **2.277 gram** hurda **altın** bulunur ve söz konusu para ve altınlar ile otobüse el konulur.

Anayasa Mahkemesi, otobüsle ilgili olarak gerçekleştirilen bu elkoyma işlemiyle, şirket ortağı başvuru bakımından mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

³⁹⁰ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet/ŞAHİN, Cumhuriyet: İnfaz Hukuku, 5. bası, Ankara, Ekim 2022, sh. 233 vd.

Keza, bir şirket, bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde, **suç işlemek suretiyle ya da suç işlemek dolayısıyla elde edilmiş maddi menfaatlerin** sermaye olarak konulmasıyla kurulmuş olabilir. Bu durumda **konu** itibarıyla bu şirkete ait olan bütün malvarlığı değerlerinin müsadere hukumlarına hükmedilmesi gerekir. Zira, bu durumda şirketin sermayesi, suç işlemek suretiyle ya da suç işlemek dolayısıyla elde edilmiş olan malvarlığı değerlerinden oluşmaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu durumda şirket ortaklık paylarının görünüşte gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde olması, müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Zira, bu durumda müsadere edilen şirket ortaklık payları, **suç işlemek suretiyle ya da suç işlemek dolayısıyla elde edilmiş maddi menfaatlardan** oluşmaktadır.

Yargılama sürecinde şirket ortağının ölmüş olması, kendisi hakkında artık ceza-ya hükmedilebilme imkanı kalmadığı için kendisi hakkındaki **ceza davasının düşmesine karar** verilmesini gerektirir. Sanık hakkında ölümü sebebiyle ceza davasının düşmesine karar verilmesi, iddianamede dava konusu suç bağlamında müsadere talep edilen malvarlığı değerleri ile ilgili olarak müsadere davasının görülmesine engel teşkil etmez.

Müsadere davasının devamı sürecinde ölen sanığın mirasçılarına, suçtan zarar gören sıfatıyla davaya katılma imkanının tanınmasının gerekli olduğu kanaatindeyim.

Verilmiş olan mahkumiyet hükmüyle ilgili kanun yolu incelemesi aşamasında sanığın ölmüş olması halinde ise, sanıkla ilgili ceza davasının düşmesine karar verilmesi gerekir. Yani bu durumda sanık hakkındaki dava, ceza yaptırımları yönünden düşer. Bu davada ayrıca müsadereye hükmedilmiş ise, bu müsadere hükmünün yukarıda izah ettiğim çerçevede hukuka uygun olarak verilmiş olduğu kanaatine varılmış olması halinde, bu müsadere hükmünün onanmasına karar verilir. Kanun yolu incelemesi sürecinde ölenin mirasçılarına davaya katılma imkanı tanınmaz.

Ekskurs 4. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

“Mülkiyetin kamuya geçirilmesi” yaptırımı, Kabahatler Kanununun 16. maddesinde bir *idari tedbir* olarak kabul edilmiştir (f. 2). Söz konusu maddenin gerekçesinde bu yaptırımın müsadere ile ilgisini ortaya koyan şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Türk Ceza Kanununda müsadere, suç karşılığında bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir. Buna karşılık, ... kavram kargaşasına neden olmamak için, (Kabahatler Kanununda) kabahatlerle bağlantılı olarak müsadere kavramı yerine, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ifadesi kullanılmıştır. Bu yaptırımın konusunu oluşturan eşya ve sair malvarlığı değerinin mülkiyetinin Devlete veya sair bir kamu kurum ve kuruluşuna geçmesi

söz konusu olabileceği için, mülkiyetin Devlete geçirilmesi ifadesi değil, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ifadesi benimsenmiştir.”³⁹¹.

Kabahatler Kanununun 18. maddesinde “mülkiyetin kamuya geçirilmesi” yaptırımını ile ilgili olarak genel bir düzenleme yapılmıştır:

“Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

MADDE 18- (1) *Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.*

(2) *Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın;*

a) Kullanılmaz hale getirilmesi,

b) Niteliğinin değiştirilmesi,

c) Ancak belli bir surette kullanılması,

Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında koşulun yerine getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(3) *Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.*

(4) *Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer.*

(5) *Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında idari para cezası veya başka bir idari yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.*

(6) *Kaim değer mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.*

(7) *Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha edilir.*

(8) *Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir.”*

Söz konusu madde gerekçesinde, mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının müsadereinden farkını açıkça ortaya koyan şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Madde metninde, bir idari tedbir olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbirine ancak ilgili kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir. Müsadereinden farklı olarak, mül-

³⁹¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840.

kiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, **idari nitelikte bir karardır**. Bu tedbirin konusunu, ancak **kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşya** oluşturabilir.

İkinci fıkra, bu tedbire karar verilmesinin belli bir süre geciktirilebileceği koşullar belirlenmiştir. Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşya, fail tarafından örneğin yurda sokulmadan belli bir süre içinde başka bir ülkeye götürülüp kullanıldığı, kullanılamaz hale getirildiği veya sahibine iade edildiği takdirde mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmeyebilecektir.

Üçüncü fıkra, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmeden önce, kamu görevlileri tarafından eşya üzerinde kısa süreli elkoyma tedbirine başvurma imkânı tanıyan bir düzenleme yapılmıştır.

Dördüncü fıkra, bu tedbirin konusunu oluşturan eşyanın mülkiyetinin, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçeceği kabul edilmiştir.

Beşinci fıkradaki düzenlemeyle mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının, bir **idari tedbir niteliğinde yaptırım** olduğu vurgulanmıştır.

Altıncı fıkra **kaim değer mülkiyetinin kamuya geçirilmesine** karar verilebileceği kabul edilmiştir. Kaim değer kavramından ne anlaşılması gerektiği hususuyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsadereğine ilişkin madde metinleri ve gerekçelerine bakılmalıdır.

(Yedinci) fıkra, mülkiyeti kamuya geçirilen eşyanın imhasına ilişkin koşul belirlenmiştir.³⁹²

XIX. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri

Yeni TCK'nın 56. maddesinde, “Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir.” denmektedir³⁹³. Bu yollama gereğince çocuklara özgü güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak 5395 s. **Çocuk Koruma Kanununda** düzenleme yapılmıştır. Söz konusu Kanuna göre;

“Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır.” (m. 11).

Koruyucu ve destekleyici tedbirler de söz konusu Kanunun 5'inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

³⁹² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840.

³⁹³ Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri hakkında ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. BALO, Yusuf Solmaz: *Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması*, Ankara, 2005.

“Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;

a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,

d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına,

e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,

Yönelik tedbirdir.” (m. 5, f. 1).

Ayrıca belirtmek gerekir ki; *“suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren çocuklar hakkında, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.” (5395 s. ÇKK, m. 12).*

XX. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri

İnsan, maruz kaldığı akıl hastalığının etkisiyle, davranışlarının hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneğinden veya davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğinden yoksun olabilmektedir. Bu nedenledir ki, maruz kaldığı akıl hastalığının etkisinde kalarak suç teşkil eden bir fiil işleyen kişinin kusur yeteneğinin olmadığı kabul edilmektedir.

Kanunun 32'nci maddesinde *“akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.”* denilmek suretiyle, kişinin ceza hukuku sorumluluğu bakımından, akıl hastalığının davranışları üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmuştur.

Akıl hastası olması nedeniyle işlediği fiille ilgili olarak kusur yeteneği ve ceza sorumluluğu olmayan kişi hakkında, mahkemece akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmolunur.

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirinin özelliklerinden birisi, bunun **koruma ve tedavi amacına** yönelik olmasıdır. Uygulanan güvenlik tedbiriyle toplumun ve ailesinin akıl hastasına karşı korunmasının yanı sıra, akıl hastasının tedavi edilmesinin de amaçlanması gerekmektedir. Bu bakımdan akıl hastasına özgü güvenlik tedbiriyle sadece koruma veya sadece tedavi amacı güdülemez.

Akıl hastasının toplum açısından oluşturduğu **tehlikelilik** durumu gözönünde bulundurularak, hakkında güvenlik tedbirine hükmolunmaktadır (TCK, m. 57)³⁹⁴. 765 s. TCK’da, suçun “ağır cezalı” bir suç olması durumunda muhafaza ve tedavi altında bulundurma süresinin bir yıldan az olamayacağı kabul edilmişti (m. 46, f. 3)³⁹⁵. Buna karşılık, yeni TCK’da akıl hastası hakkında hükmolunacak güvenlik tedbirinin süresiyle ilgili olarak bir asgari sınır getirilmemiştir.

Hakkında hükmolunan güvenlik tedbirinin süresi, akıl hastasının **toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalkmasına** veya **önemli ölçüde azalmasına** bağlı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle, 765 s. Kanundan farklı olarak, yeni TCK’da güvenlik tedbirinin süresi akıl hastasının iyileşmesine bağlı kılınmamıştır.

Akıl hastası hakkında uygulanan güvenlik tedbirinin sona erdirilmesine **infaz hakimliği** karar vermeye yetkilidir (m. 57, f. 2).

İnfaz hakimi, akıl hastasının yerleştirildiği kurumun **sağlık kurulu raporu** üzerine bu kararı verebilecektir (m. 57, f. 2, 3). Bu rapora istinaden verilen infaz hakimisi kararıyla, akıl hastası tamamen serbest bırakılabileceği gibi, “*tıbbî kontrol ve takibi*” yapılmak suretiyle yani denetimli olarak serbest bırakılabilir. Sağlık kurulu raporunun infaz hakimini bağlayıcı olmadığını belirtmek gerekir.

³⁹⁴ “Yeni ceza adalet sistemimizde akıl hastalığı; kusur yeteneğini etkilemesi nedeniyle, ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden birisi olarak düzenlenmiştir. Buna göre, ortada tüm unsurlarıyla oluşmuş bir suç bulunmakta ise de; akıl hastası olduğu saptanan sanık, işlemiş bulunduğu fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamayacak durumda olduğundan, bu suçun işlenmesinden dolayı hukuki anlamda “kınanamaz”, yani sorumlu tutulup cezalandırılmaz. Dolayısıyla, 5237 sayılı Yasanın 32/1. maddesi gereğince bu durumdaki sanığa ceza tayin edilmesi mümkün bulunmadığından, 5271 sayılı Yasanın 223/3-a maddesi uyarınca “ceza verilmesine yer olmadığı” hükmünün verilmesi gerekir. Ancak, sanığa ceza verilemiyor olması, sanık hakkında 5237 sayılı Yasanın 57. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri uygulanmasına engel değildir.

... 5237 sayılı Yasanın 57/2. maddesinde; “**Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre, güvenlik bakımından kişinin tıbbi kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyorsa bunun süre ve aralıkları belirtilir**” biçiminde (hükme) yer verilmiş olması; akıl hastalığının saptanması durumunda yapılacak uygulamanın sınırlarını belirleme açısından, işlenen fiilin bir suç oluşturup oluşturmadığını, eğer oluşturuyor ise suç vasfının belirlenmesini ve gerek sübuta ve gerekse vasa ilişkin gerekçeli değerlendirmenin hükme dercedilmesini zorunlu kılmaktadır.” (CGK, **20.3.2012**, E. 2011/1-451, K. 2012/115).

³⁹⁵ Yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısında da muhafaza ve tedavi süresinin bir yıldan az olamayacağı yönünde hüküm bulunmaktaydı (m. 34, f. 2). Ancak, 765 s. Kanundan farklı olarak, bu asgari süre bakımından, işlenen suç veya cezası gözönünde bulundurulmamaktaydı.

Akıl hastasının “*tıbbî kontrol ve takibi*” yapılmak suretiyle yani denetimli olarak serbest bırakılması halinde, bu “*tıbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır.*” (m. 57, f. 4).

Serbest bırakılan akıl hastasının toplum açısından tehlikeliliğinin artması halinde, hakkında “*infaz hakimliğince yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine*” karar verilir (m. 57, f. 5). Ancak, bu karar, akıl hastasının tıbbi kontrol ve takibinin yapıldığı “*teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşun*”ca hazırlanan **sağlık kurulu raporuna** istinaden verilebilir.

XXI. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri

A. Tekerrürün Hukuki Niteliği

765 sayılı Kanundan farklı olarak³⁹⁶, yeni TCK’da tekerrür nedeniyle cezanın artırılması yoluna gidilmemektedir. Suç işlemede tekerrür hali, kişinin diğer suçlara nazaran toplum açısından daha fazla tehlikeli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle tekerrür, yeni TCK’da, “*kişinin daha önce işlediği suç nedeniyle belli bir cezaya mahkûm edilmiş olmasına rağmen suç işlemede gösterdiği kararlılıkla toplum açısından tehlikeliliğinin ifadesi*” olarak kabul edilmiştir (Bkz. TCK, m. 58 gerekçesi).

İfade ettiği haksızlık bakımından, ilk defa işlenen suçla mükerreren işlenen suç arasında bir fark bulunmamaktadır. Keza, işlenen suçtan dolayı kusurluluk bakımından da böyle bir farklılık söz konusu değildir. Bu itibarla, ondokuzuncu yüzyıl ceza hukuku düşüncesine hakim olan klasik suç teorisinin tekerrürü cezayı artıran bir neden olarak kabul eden yaklaşımı³⁹⁷, yeni TCK’nın sisteminde terkedilmiştir.

Bu itibarla, yeni TCK’nın sisteminde tekerrür,

- a) hapis veya adli para cezasının seçimlik olarak öngörüldüğü hallerde,
- b) kişi hakkında hükmolunan hapis cezasının infazı sürecinde koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanması ile bağlantılı olarak ve ayrıca,
- c) mahkum olduğu hapis cezasının infazından sonra kişi hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanması ile bağlantılı olarak,

dikkate alınacaktır.

³⁹⁶ Yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısında da, tekerrür cezanın artırılması sebebi olarak kabul edilmişti (m. 48).

³⁹⁷ Bu görüşlerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: ÜZÜLMEZ, İlhan: *Türk Hukukunda Tekerrür*, Ankara, 2003; EREM, Faruk: *Tekerrürün Esası*, in: Adalet Dergisi, sayı 10, yıl 1949, sh. 1417 vd.; OKAY, Sadık: *Tekerrürün Mahiyeti Hakkında Başlıca Nazariyeler ve Tatbikata Tesirleri*, in: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt IX, sayı 12, sh. 331 vd.

B. Tekerrürün Koşulları

Yeni TCK'nın 58. maddesindeki düzenlemeye göre tekerrürün koşulları şunlardır:

Birinci koşul: Kişi, önceden işlediği bir suç nedeniyle hapis veya adli para cezasına mahkum edilmiş olmalıdır.

Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, “*önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi*” gerekir³⁹⁸. Kişi, önceden işlediği suçtan dolayı bir cezaya mahkum edildikten sonra yeni bir suç işlemelidir. Maddenin bir ve ikinci fıkralarının birlikte göz önünde bulundurulması halinde; kişinin, daha önce işlediği suç nedeniyle bir **cezaya mahkum edilmiş olması** gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak, mahkum edildiği cezanın **hapis veya adli para cezası** olması, tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi bakımından önemli değildir³⁹⁹.

Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, daha önceki cezaya ilişkin mahkumiyet hükmünün **infaz edilmiş olması gerekmektedir**.

Daha önce işlemiş bulunduğu suç nedeniyle kişi hakkında hükmolunan hapis cezasının ertelenmiş olması halinde, denetimli serbestlik süresi dolmuş olsun

³⁹⁸ Yargıtay Ceza Genel Kurulu, mükerrer hakkında kurulan mahkumiyet hükmünde “**tekerrüre esas alınan ilamın gösterilmesine gerek olmadığı**” yönünde içtihatla bulunmuştur:

Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/3-1372, K. 2013/329; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/15-1351, K. 2013/328; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/13-1436, K. 2013/326; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/9-1465, K. 2013/325; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/6-1434, K. 2013/324; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/6-1432, K. 2013/323; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/6-1435, K. 2013/322; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2013/8-228, K. 2013/321; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2013/8-134, K. 2013/320; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2013/13-245, K. 2013/319; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/13-1495, K. 2013/318; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/13-1493, K. 2013/317; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/13-1332, K. 2013/316; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2013/10-51, K. 2013/315; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/6-1542, K. 2013/314; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/6-1491, K. 2013/313; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/6-1454, K. 2013/312; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/3-1328, K. 2013/310; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/13-1302, K. 2013/309; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2013/8-129, K. 2013/308; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2013/8-54, K. 2013/307; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2013/13-4, K. 2013/306; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/13-1444, K. 2013/305; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2013/8-151, K. 2013/304; Yargıtay CGK, **18.6.2013**, E. 2012/6-1441, K. 2013/303.

Yargıtay'ın bu kabulünü doğru bulmamaktayız. Kararın gerekçesinde, hakkında mahkumiyet hükmü kurulan kişinin daha önce işlediği hangi suçtan mahkumiyeti sebebiyle mükerrer olduğunun belirtilmesi gerekir. Bu durum, tekerrürle ilgili olarak Kanunda belirlenen süreler bakımından büyük önem taşımaktadır..

³⁹⁹ Ancak belirtmek gerekir ki, önceden işlenen suç nedeniyle mahkum olunan adli para cezasının kanun gereği olarak kesin olduğunun kabul edildiği ve dolayısıyla, bu cezaya mahkumiyet hükmü ile ilgili olarak temyiz kanun yolunun kapalı olduğu hallerde, bu ceza tekerrür hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz. (Bkz. CGK, **26.10.2010**, E. 2010/2-168, K. 2010/216; CGK, **16.6.2009**, E. 2009/2-110, K. 2009/167; CGK, **5.5.2009**, E. 2009/2-2, K. 2009/115.

veya olmasın, yeniden işlediği suç nedeniyle tekerrür hükümleri uygulanabilecektir. Bu bakımdan, yeni TCK'nın sistemi 765 s. Kanundan farklılık arz etmemektedir. Zira, 765 s. Kanuna göre deneme süresinin iyi halli olarak geçirilmesi durumunda mahkumiyet esasen vaki olmamış sayılacağı için, bu mahkumiyet deneme süresinden sonra işlenen suçla ilgili olarak tekerrür hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınamamaktaydı.

Buna karşılık, daha önce işlemiş bulunduğu suç nedeniyle kişi hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olması, tekerrür hükümlerinin uygulanmasını gerektirmez. Bu itibarla, örneğin kişinin önceden mahkum edildiği kısa süreli hapis cezasının seçenек yaptırım olarak güvenlik tedbirine çevrilmesi halinde (m. 50), daha sonra işlediği suç nedeniyle hakkında tekerrür hükümleri uygulanamaz.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, *“fili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.”* (m. 58, f. 5). Bu itibarla, onsekiz yaşından küçük olan kişinin, işlemiş bulunduğu suçtan dolayı hapis veya adli para cezasına mahkum edilmiş olması halinde; bu mahkumiyet, bilahare işleyeceği suçlardan dolayı tekerrür hükümlerinin uygulanmasını gerektirmez. Bilahare işlenen suçun onsekiz yaşın doldurulmasından önce veya sonra işlenmesinin bir önemi bulunmamaktadır.

İkinci koşul: Önceki mahkumiyet hükmünün infazından itibaren belli bir süre içinde yeni bir suçun işlenmiş olması gerekir.

Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, sonradan işlenen suçla ilgili olarak bir **süre sınırlaması** getirilmiştir. Böylece, süresiz bir tekerrür sistemi benimsenmemiştir. Yeni TCK'nın sisteminde, tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, önceki mahkûmiyetin infaz edilmiş olması gerekmemeyle birlikte⁴⁰⁰; **tekerrüre ilişkin sürelerin işlemeye başlaması bakımından önceki mahkûmiyetin infaz edilmiş olması aranmıştır**^{401,402}.

⁴⁰⁰ Yeni TCK'na ilişkin Hükümet Tasarısında da, tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, önceki mahkumiyet hükmünün infaz edilmiş olması şartı aranmamıştı. Bu hususla ilgili olarak Hükümet Tasarısının 48. maddesinin gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmişti:

“765 sayılı Kanunun uygulanmasında tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki suç nedeniyle verilen cezanın infaz edilmesi koşulu aranmakta ve bu durum Yargıtay içtihatlarıyla da yerleşmiş bulunmaktadır.

Ancak, bu uygulama, özellikle, infazdan kaçan kişi yönünden bir olanak sağlamakta, firar eden suçluya ödül verilmesi gibi bir neticenin ortaya çıkmasını sonuçlamaktadır. Hâl böyle olunca, suçta tekerrürle mücadele, etkisini büyük ölçüde kaybetmektedir. Mükerrerlerle mücadele etmenin doğru yolunun infaz koşulunun aranmasından vazgeçmek olduğu bir gerçektir. Bu sistem kendi içinde de çelişki yaratmaktadır. Örneğin, müebbet ağır hapis cezasının hükmedildiği durumlarda, ikinci bir suç işlenmesi hâlinde, infaz koşulunun gerçekleşmemesine karşın ... 765 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre, cezanın infazının bir ölçüde ağırlaştırılması öngörülmüştür.” (TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı 664, sh. 47).

⁴⁰¹ Buna karşılık, yeni TCK'na ilişkin Hükümet Tasarısındaki düzenlemeye göre, tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, sonradan işlenen suçun önceki mahkumiyet hükmünün ke-

“Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,

b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,

geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.” (m. 58, f. 2).

sinleştigi tarihten itibaren belli bir süre içinde işlenmesi gerekmektedir (m. 48, f. 1). Aslında bu düzenleme, cezanın infazından kaçan hükümlü açısından imtiyazlı bir durum ortaya çıkardığı için, yeni TCK’ya ilişkin TBMM Adalet Alt Komisyonundaki çalışmalar sırasında eleştirilerimiz dikkate alınmak suretiyle değiştirilmiştir.

⁴⁰² Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**’nun **6.4.2010** tarihli ve E. 2010/6-48, K. 2010/74 sayılı kararında yer verilen açıklamalar, tekerrür müessesesinin hukuki mahiyeti, koşulları ve sonuçları bakımından didaktik önemi haizdir:

“Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hükmün kesinleşmesinden sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki hükmün kesinleşmesi ve ikinci suçun kesinleşmeden sonra işlenmesi yeterli olup, cezanın infaz edilmiş olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak yasa koyucu tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki cezanın infaz edilmesi koşulunu aramadığı halde, infazdan sonra belirli bir sürenin geçmesi halinde tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağına hüküm altına almıştır. Buna göre, beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, beş yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezasına mahkûmiyet halinde ise cezanın infaz tarihinden itibaren üç yıl geçmekle tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır.

5237 sayılı Yasanın 58. maddesi uyarınca **kişinin mükerrir sayılması için ilk hükmün kesinleşmesinden sonra ikinci suçun 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenmesi yeterli olup; ilk suçun 1 Haziran 2005 tarihinden önce veya sonra işlenmesinin ise mükerrirlik açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.**

Maddenin 5. fıkrasında fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış kişiler hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı, 4. fıkrasında ise tekerrüre esas alınamayacak suçlar belirtilmiştir.

Tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesinin sonucu olarak; mükerrir sanık hakkında, sonraki suç nedeniyle yasa maddesinde seçimlik ceza olarak hapis veya adli para cezası öngörülmüşse hapis cezasına hükmolunması, hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektilmesi ve hükümlü hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanması gerekmektedir.

5237 sayılı TCY’nın 58. maddesinde düzenlenmiş bulunan ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bölümde yer alan “tekerrür müessesesinin” infaz hukukundan daha çok maddi ceza hukukuna ilişkin bir “kurum” olduğu görülmektedir. Hükümlülüğün yasal sonucu olmaması nedeniyle 5275 sayılı TCY’nın 98 ve devamı maddeleri uyarınca infaz aşamasında bu konuda karar alınması mümkün değildir. Hangi mahkûmiyetin tekerrüre esas alındığı, tekerrür koşullarının bulunup bulunmadığı, hükümlü hakkında kaçınıcı kez tekerrür hükümlerinin uygulandığı ve tekerrür nedeniyle hükümlünün ceza evinde kalacağı süreye eklenecek sürenin belirlenmesi için mahkûmiyet hükmünde açıkça hangi hüküm nedeniyle kişinin mükerrir sayıldığı ve hangi mahkûmiyetin tekerrüre esas alındığının belirtilmesi gerekmektedir.”

Tekerrür müessesesine ilişkin genel açıklamalar için ayrıca bkz. CGK, **19.6.2012**, 2012/6-170, K. 2012/241; CGK, **20.3.2012**, 2011/6-383, K. 2012/113; CGK, **6.3.2012**, E. 2011/13-384, K. 2012/82; CGK, **28.2.2012**, E. 2011/6-245, K. 2012/60; CGK, **7.6.2011**, E. 2011/9-88, K. 2011/116; CGK, **13.4.2010**, E. 2010/11-39, K. 2010/90; CGK, **14.7.2009**, E. 2009/6-88, K. 2009/200; CGK, **8.4.2008**, E. 2008/1-57, K. 2008/74.

Önceki mahkumiyetin sebebini oluşturan suç kasıtlı bir suç ise, tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, sonraki suçun da kasıtlı bir suç olması gerekir. Keza, önceki mahkumiyetin sebebini oluşturan suç taksirli bir suç ise, tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, sonraki suçun da taksirli bir suç olması gerekir⁴⁰³, ⁴⁰⁴. Zira, “*kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ... arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.*” (m. 58, f. 4).

Yine, önce veya sonra işlenmiş olması arasında fark gözetilmeksizin, “*sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.*” (m. 58, f. 4).

Ayrıca, yeni TCK’da yabancı mahkeme kararlarının tekerrüre etki alanı genişletilmiştir:

“Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.” (m. 58, f. 4).

Bütün bu koşulların varlığı halinde, “*mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.*” (m. 58, f. 7)⁴⁰⁵.

⁴⁰³ “Sanık hakkında birden fazla tekerrüre esas alınabilecek hükümlülüğün bulunması halinde, bunlardan en ağırının esas alınması ve tekerrüre esas alınan ilamların da hükümde açıkça gösterilmesi gerekmektedir.” (CGK, 20.3.2012, 2011/6-383, K. 2012/113).

Ancak Ceza Genel Kurulu bilahare bu içtihadıyla çelişen bir karar vermiştir:

TCK’nın 58. maddesine ilişkin hükümlerden bahisle, “anılan kanuni düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, hükümde tekerrüre esas alınan ilamın gösterilmesine gerek olmadığı, bu durumun infaz aşamasında gözetilebileceği, sanık hakkında birden fazla tekerrüre esas alınabilecek hükümlülüğün bulunması halinde ise bunlardan en ağırının tekerrüre esas alınması gerektiği sonucuna” varılmıştır: CGK, 12.2.2013, E. 2012/13-1438, K. 2013/53; CGK, 9.4.2013, E. 2012/6-1307, K. 2013/151). Bu içtihadın kendi içinde çelişki bulunduğunu ifade etmekle yetinmemiz gerekir.

⁴⁰⁴ Öztürk/Erde, taksirli suçlarda tekerrür hükümlerinin uygulanmaması gerektiği görüşündedirler (ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 9. bası, sh. 339). Biz de bu görüşün doğru olduğu kanısındayız.

⁴⁰⁵ “TCK’nın 58. maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinin açık anlatımından, sanık hakkında hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi yeterlidir. Mükerrir sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine de açıkça hükmolunmaması ve aleyhe temyiz olmaması halinde bu husus ... aleyhe değiştirmeme ilkesi kapsamında değerlendirilemeyecektir. Zira mükerrir olan sanık hakkında cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanması, hakkındaki cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesinin zorunlu bir sonucudur.

...

Sabika kaydında tekerrüre esas olan geçmiş hükümlülüğü bulunan sanık hakkında yerel mahkemece cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine hükmolunmadan, sanığa verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi yeterli olup cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesinin zorunlu bir sonucu olan “cezanın infazın-

C. Tekerrürün Sonuçları

I. Yukarıda da belirtildiği gibi, yeni TCK'da tekerrür, kişi hakkında hüküm kurulurken ve hükmolunan hapis cezasının infazı sırasında dikkate alınacak bir neden olarak görülmüştür. 5275 sayılı *Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna* göre, mükerrerlerin koşullu salıverilmeden yararlandırılabilmesi için, diğer suçlulara nazaran daha fazla süreyle infaz kurumunda kalmaları gerekmektedir:

“Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,

c) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki yılının,

*d) Süreli hapis cezasının **üçte ikisinin,***

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.” (İnfaz K, m. 108, f. 1).

Ancak, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve terör suçları gibi, koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkum olunan cezanın dörtte üçünün infaz kurumunda çekilmesini gerektiren suçlar tekerrür halinde işlense bile bu oran değişmeyecektir.

İlk defa suç işlemiş olan kişi bu nedenle mahkum olduğu örneğin **altı yıl** hapis cezasının **üç yılını** infaz kurumunda iyi halli olarak çektiği takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir. Buna karşılık, mükerrer hükümlü, mahkum olduğu altı yıllık hapis cezasının **dört yılını** infaz kurumunda iyi halli olarak çekmesi gerekir ki, koşullu salıverilmeden yararlanabilsin. Bu konuda, koşullu salıverilmeye ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalara bakılmalıdır.

Ancak, İnfaz Kanununda, tekerrür nedeniyle infaz kurumunda çekilmesi gereken ilave süreye bir sınırlama getirilmiştir (m. 108, f. 2). Buna göre, *“tekerrür nedeniyle koşullu salıver(ıl)me süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.”*

Yukarıdaki örnekte tekerrüre esas teşkil eden önceki suçtan dolayı mahkum olunan hapis cezası bir yıl veya daha fazla ise, bir sorun bulunmamaktadır. Ancak, mükerrer hükümlü, tekerrüre esas teşkil eden önceki suçundan dolayı mahkum olduğu hapis cezası bir yıldan az ise, örneğin **altı ay** ise; işlediği ikinci suçtan dolayı mahkum olduğu altı yıllık hapis cezasının **üç yıl altı aylık** kısmını infaz kurumunda iyi halli olarak çekmesi halinde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir.

dan sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına" açıkça hükmolunmaması aleyhe bozma yasağı kapsamında değerlendirilemez.”: CGK, 17.2.2015, E. 2013/8-451, K. 2015/6).

Mükerrir hükümlünün tekerrüre esas teşkil eden birden fazla suçu bulunabilir. Bu durumda mükerrir hükümlünün sonradan işlediği suçtan dolayı mahkum olduğu hapis cezasının infazı sürecinde koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi için, tekerrür nedeniyle infaz kurumunda geçirmesi gereken ilave süre, tekerrüre esas teşkil eden suçlardan dolayı mahkum olduğu en uzun süreli hapis cezasından fazla olamayacaktır.

Kişi tekerrüre esas teşkil eden önceki suçundan dolayı adli para cezasına mahkum edilmiş olabilir. Bu durumda, mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanacağı sonraki suçla ilgili olarak mahkum olunan hapis cezasının infazında koşullu salıverilme bakımından nasıl bir yöntem izleneceği hususunda bir sorunla karşılaşılmaktadır. Zira, İnfaz Kanununun 108. maddesinin ikinci fıkrası, sadece hapis cezası göz önünde bulundurularak formüle edilmiştir.

Bu durumda izlemesi gereken yöntem, kanaatimizce şöyle olmalıdır: Tekerrüre esas teşkil eden önceki suçtan dolayı mahkum olunan adli para cezasının karşılığı olan gün sayısı, TCK'nın 63. maddesi hükmüne göre belirlenmelidir (100 Türk Lirası = 1 gün). Bu suretle bulunan gün sayısı, sonraki suçla ilgili olarak mahkum olunan ve mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilecek hapis cezasının infazında koşullu salıverilme bakımından İnfaz Kanununun 108. maddesinin ikinci fıkrası bağlamında göz önünde bulundurulmalıdır.

“Tekerrür hâlinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.” (m. 58, f. 3).

Örneğin taksirle yaralama suçunun temel şeklinin karşılığında hapis ve adli para cezası seçenek cezalar olarak belirlenmiştir (m. 88, f. 1). Daha önce işlenmiş olan bir taksirli suç sebebiyle mahkumiyet hükmü kurulduktan sonra, taksirle yaralama suçu işlenmiş ise, tekerrür hükümlerinin uygulanması gerekir. TCK'nın 58. maddesinin üçüncü fıkrasına göre bu durumda taksirle yaralama suçundan dolayı adli para cezasına hükmedilemez. Bu durumda hükmolunan hapis cezası, TCK 50. maddesine göre adli para cezasına çevrilemez. Aksi takdirde, 58. maddenin üçüncü fıkrasının bir anlamı olamaz. Bu sebeple Ceza Genel Kurulu'nun bu yöndeki kararları⁴⁰⁶ doğrudur.

Ancak, belirtmek gerekir ki, TCK'nın sisteminin aksine, çeşitli kanunlarda yer alan bazı suç tanımlarında sadece adli para cezası öngörülmektedir. Sadece adli para cezasını gerektiren bütün bu suçlar, önödemeye tabi bulunmaktadır (m. 75). Önödeme kararı bir mahkumiyet olmadığı için tekerrüre esas teşkil etmemektedir. Önödeme kapsamına girmesine rağmen, kişi adli para cezasına mahkum edilmiş olabilir. Bu mahkumiyetin tekerrüre esas teşkil edebileceği hususu izahtan varestedir. Buna karşılık, TCK'nın sisteminin gereği olarak, sadece adli

⁴⁰⁶ Bkz. CGK, 1.3.2013, E. 2012/2-1500, K. 2013/95.

para cezasını gerektiren suçlardan dolayı mahkum olunan adli para cezası bakımından mükerrirlere özgü infaz rejimi öngörülmemiştir.

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, “*ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.*” (İnfaz K, m. 108, f. 3).

II. Yeni TCK’da tekerrür, ayrıca, mahkum olduğu hapis cezasının infazından sonra kişi hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının nedeni olarak görülmüştür.

Yeni TCK’nın 58’inci maddesinde, mükerrir hakkında mahkum olduğu hapis cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanması yönünde *emredici* bir ifade kullanılmıştır (f. 6).

Bu itibarla, mahkeme, hüküm tesis ederken, “*mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler.*” (İnfaz K, m. 108, f. 4). Mahkemece bu sürenin uzatılmasına karar verilebilir. Sürenin uzatılmasına ilişkin karar, hükümde belirlenen denetim süresi dolmadan önce, denetimli serbestlik bürosu görevlilerince hükümlü hakkında hazırlanan raporda belirlenen hususlar göz önünde bulundurularak verilir. Bu süre, en fazla beş yıla kadar uzatılabilir (İnfaz K, m. 108, f. 6)⁴⁰⁷.

Yeni İnfaz Kanununa göre, “*tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır.*” (İnfaz K, m. 108, f. 5). Bu hükmün gereği olarak, mükerrir hükümlü cezanın infazının tamamlanmasından sonra işleyecek olan denetim süresi zarfında da **denetimli serbestlik tedbirine** tabi tutulacaktır.

Buna göre; mükerrir “*hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı*

⁴⁰⁷ Uygulamada, mükerrir suçlu hakkında cezanın infazı tamamlandıktan sonra uygulanacak olan denetimli serbestlik tedbirinin süresine, mahkumiyet hükmü ile birlikte karar verildiğini gözlemlemekteyiz.

Ancak, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun son kararlarıyla, bu yanlışlığın önüne geçilmesi yönündeki ısrarlı talebimiz dikkate alınmıştır:

“5275 sayılı Yasanın mükerrirlere özgü infaz rejimini düzenleyen 108. maddesinin (4), (5) ve (6). fıkralarında “*Hakim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıvermeye ilişkin hükümler uygulanır. Hakim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir*” hükmüne yer verilmiştir.

... Denetim süresini belirleme ve gerektiğinde uzatma görevi, hükmü veren mahkemeye değil, hükümlünün infaz aşamasındaki davranışlarını da değerlendirerek koşullu salıverme ile ilgili kararı verecek olan mahkemeye aittir. Buna göre hükümlülük kararında mükerrir olan sanık hakkında 5237 sayılı TCY’nın 58/6-7. maddeleri gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, yargılamayı yapan mahkemece infaz aşamasında belirlenecek bir konuda infazı kısıtlayacak şekilde denetim süresi belirlemesi yasal değildir.” (CGK, 12.7.2011, E. 2011/7-173, K. 2011/174).

meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılabilir.” (İnfaz K, m. 107, f. 7).

Keza, “*infaz hâkimi denetim süresinde (mükerrir) hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda (mükerrir) hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; (mükerrir) hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek infaz hakimine verir. İnfaz hâkimi ayrıca, iki yılı geçmemek üzere denetim süresi içinde hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne belirlenecek yükümlülüklerle tabi tutulmasına karar verebilir. Bu karar gereğince denetimli serbestlik müdürlüğü, risk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hükümlüyü;*

- a) Belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma,*
- b) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme,*
- c) Belirlenen programlara katılma,*

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutar. Denetimli serbestlik müdürlüğü hükümlünün risk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilir.” (İnfaz K, m. 107, f. 9).

Mükerrir hükümlü, cezanın infazının tamamlanmasından sonraki denetim süresi içinde yeni bir suç işlemiş olabilir. Bu durumda, hükümlü hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanabilecektir. “*İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü (işlediği yeni suçtan dolayı mahkum olduğu hapis cezasının infazında) koşullu salıverilme*”yecektir (İnfaz K, m. 108, f. 3).

Mükerrir hükümlü, cezanın infazının tamamlanmasından sonraki denetim süresi içinde kendisine yüklenen yükümlülüklerle, infaz hakiminin uyarısına rağmen, aykırı davranmakta ısrar edebilir. 6545 sayılı Kanunla İnfaz kanununun 108. maddesinde yapılan değişiklikle bu duruma özgü olarak **özel bir yaptırım** öngörülmüştür:

*“Cezanın infazı tamamlandıktan sonra devam eden denetim süresi içinde, bu madde hükümlerine göre kendilerine yüklenen yükümlülüklerle ve yasaklara aykırı hareket eden mükerrirler, infaz hâkimi kararı ile **disiplin hapsine** tabi tutulur. Disiplin hapsinin süresi **on beş günden az ve üç aydan fazla** olamaz.” (İnfaz K, m. 108, f. 7)*

Aslında, diğer suçlulara nazaran toplum açısından daha fazla tehlike ifade eden bu kişilerin mahkum oldukları hapis cezasının infazının tamamlanmasından sonra da denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması, bu hükümlüler açısından başlı başına bir yaptırım niteliği taşımaktadır. Böylece bu hükümlüler, cezalarını çekmiş olsalar bile, kontrolsüz ve başıboş olarak toplum içine salınmayacaklardır.

Burada çözüm aranması gereken sorun, söz konusu hükümlülerin denetim süresi içinde kendisine yüklenen yükümlülüklerle aykırı hareket etmesi veya yeni bir suç

işlemesi halinde haklarında nasıl bir yaptırım uygulanacağı noktasında değil; bu hükümlülerle ilgili olarak uygulanan denetimli serbestlik tedbirini nasıl daha etkin hale getirip de, denetim süresi içinde kendilerine yüklenen yükümlülüklerle uygun davranmalarını sağlamakta ve yeni bir suç işlemelerini önlemekte temerküz etmektedir.

III. Kanunlarda, belirli suçlarla bağlantılı olarak, mükerrerler ile diğer tehlikeli suçlular hakkında özel güvenlik tedbirleri öngörülebilir. Örneğin cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından dolayı mükerrir veya itiyadi suçlu durumundaki failler hakkında, denetim süresi zarfında, özel bir güvenlik tedbiri olarak, **testosteron azaltıcı tedaviye** tabi tutma ve hatta, kısırlaştırma uygulaması yapılabilmelidir.

Yukarıda koşullu salıverilme bağlamında açıklandığı üzere, 6545 sayılı Kanunla İnfaz Kanununun 108. maddesinde yapılan değişiklikle, bu düşüncelerimiz kısmen dikkate alınarak, belirli cinsel suçların failleri ve sair suç ortakları hakkında, mükerrir olup olmadıklarına bakılmaksızın, koşullu salıverme ve hatta cezanın infaz kurumundaki infazı sürecinde **tedbir** olarak uygulanacak **özel yükümlülükler** öngörülmüştür. Buna göre, TCK'nın,

- a) 102'nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan,
- b) 103'üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan,
- c) 104'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan,

dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında, **cezanın infaz kurumundaki infazı sürecinde ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde,** aşağıdaki **tedavi** veya **yükümlülüklerden bir veya birkaçına** infaz hâkimi tarafından **karar verilir:**

- a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak,
- b) Tedavi amaçlı programlara katılmak,
- c) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak,
- d) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşımdan yasaklanmak,
- e) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak,
- f) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak (İnfaz K, m. 108, f. 9)⁴⁰⁸.

⁴⁰⁸ Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik”te (RG: 26 Temmuz 2016/29782) bu bağlamda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.

Ancak, söz konusu suçların failinin ve sair suç ortağının çocuk olması halinde, çocukla ilgili olarak bu tedbirler uygulanmaz (İnfaz K, m. 108, f. 10).

D. Diğer Tehlikeli Suçlara İlişkin İnfaz Rejimi

Yeni TCK, mükerrirler gibi, itiyadî suçluyu, suçu meslek edinen kişiyi ve örgüt mensubu suçluyu, toplum açısından diğer suçlulara nazaran daha fazla tehlikeli kabul etmektedir.

Bu nedenle, “mükerrirlere özgü infaz rejimi... ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri... itiyadî suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da” uygulanacaktır (m. 58, f. 9).

Bu Yönetmelik hükümlerine göre,

“Tıbbi tedavi: Cinsel suç işlemiş hükümlü hakkında ilgili kurul tarafından uygun görülen psikiyatrik veya farmakolojik tedaviyi,” (m. 4, f. 1, bent i)

“Hükümlü: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102/2, 103/1-2 ve 104/2-3 maddelerinde sayılan suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olan kişiyi,” (m. 4, f. 1, bent e)

“Yükümlü: (yine söz konusu suçlardan dolayı) haklarında yükümlülük kararı verilen, denetim altına alınan veya tedbir kararı verilen ve denetimli serbestlik müdürlüğünce toplum içinde denetimi, takibi yapılan ve iyileştirilmesine çalışılan hükümlüyü,” (m. 4, f. 1, bent k)

ifade etmektedir.

“**Tedavi**, tanımda belirtilen hükümlülere yönelik olmak üzere, ayakta veya yatarak, ilaçla veya ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel dürtünün azaltılmasına veya denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntemdir.” (m. 7, f. 1)

Belirtmek gerekir ki, Danıştay, bu fıkra ile ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir (Danıştay 10. Daire, 7.6.2017, E. 2016/12975; Danıştay 10. Daire, 7.6.2017, E. 2016/16076).

Keza, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre;

“**Tedavi amaçlı programa katılma**, hükümlülerin yeniden cinsel suç işlemelerini önlemek amacıyla ihtiyaç duyulan tedavi ve iyileştirme programları ile grup çalışmalarına veya bireysel çalışmalara katılma yükümlülüğüdür.” (m. 8, f. 1).

“**Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanma**, hükümlünün mağdurun korunması amacıyla mağdurun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesine mazereti olmaksızın ve izin olmaksızın ikamet etmekten yasaklanması yükümlülüğüdür.” (m. 9, f. 1).

“**Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşımdan yasaklanmak**, hükümlünün mağdurun korunması amacıyla mağdurun olağan hayatını sürdürdüğü yerlere mazereti olmaksızın ve izin olmaksızın yaklaşmaması ve gitmemesi yükümlülüğüdür.” (m. 10, f. 1).

“**Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak**, hükümlünün toplum ve çocukların korunması amacıyla kişinin kişisel ve sosyal durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak çocuklar ile bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanması yükümlülüğüdür.” (m. 11, f. 1).

“**Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak**, hükümlünün toplum ve çocukların yararı ve korunması amacıyla kişinin kişisel ve sosyal durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanması yükümlülüğüdür.” (m. 12, f. 1).

Yeni TCK'ya göre;

“İtiyadî suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,” (m. 6, f. 1, bent h)

“Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya almış kişi,” (m. 6, f. 1, bent i)

“Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi,” (m. 6, f. 1, bent i)

anlaşılmalıdır.

Yeni TCK'nın 58'inci maddesinin son fıkrası hükmü gereği olarak, *itiyadî suçlular* ve *suçu meslek edinen kişiler* hakkında, yeni İnfaz Kanununda mükerrerlerle ilgili olarak belirlenen koşullu salıverilme hükümleri (m. 108, f. 1, 2) uygulanacaktır.

Buna karşılık, *örgüt mensubu suçlular* açısından İnfaz Kanununda ayrı bir koşullu salıverilme hükmüne yer verildiği için (İnfaz K, m. 107, f. 4); bu hükümler hakkında, İnfaz Kanununda mükerrerlerle ilgili olarak belirlenen koşullu salıverilme hükümleri (m. 108, f. 1, 2) uygulanamayacaktır.

Bu itibarla, mahkeme hüküm tesis ederken, hakkında hüküm verdiği kişinin *itiyadî suçlu*, *suçu meslek edinen kişi* veya *örgüt mensubu suçlu* olduğunu açıkça belirtmesi gerekmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; *itiyadî suçlular*, *suçu meslek edinen kişiler* ve *örgüt mensubu suçlular* hakkında, hüküm tesis edilirken, mahkum oldukları hapis cezasının infazının tamamlanmasından sonra başlamak üzere denetim süresi belirlenecektir (m. 58, f. 6 delaletiyle İnfaz K, m. 108, f. 4).

Bu suçlular hakkında da, mahkum oldukları hapis cezasının infazının tamamlanmasından sonra işlemek üzere belirlenen denetim süresinde, **denetimli serbestlik tedbiri** uygulanacaktır (İnfaz K, m. 108, f. 5 delaletiyle, m. 107, f. 7 ve 9).

E. Terör Suçları Dolayısıyla Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Özel Tekerrür

Yukarıda da açıklandığı gibi, yeni TCK'da tekerrür, ayrıca, mahkum olduğu hapis cezasının infazından sonra kişi hakkında **denetimli serbestlik tedbiri** uygulanmasının nedeni olarak görülmüştür (m. 58, f. 6; ayrıca bkz. İnfaz K, m. 108, f. 4, 5, 6)⁴⁰⁹.

Terörle Mücadele Kanununun 17. maddesinin birinci fıkrası hükmü karşısında; mahkeme, hüküm tesis ederken, **örgüt mensubu olup olmadığına bakmaksızın**,

⁴⁰⁹ Tekerrür ve denetimli serbestlik tedbiri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, TCK Gazi Şerhi, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 699 vd.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum ettiği kişi “*hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler.*” (İnfaz K, m. 108, f. 4).

Mahkemece bu sürenin uzatılmasına karar verilebilir. Sürenin uzatılmasına ilişkin karar, hükümde belirlenen denetim süresi dolmadan önce, denetimli serbestlik bürosu görevlilerince hükümlü hakkında hazırlanan raporda belirlenen hususlar göz önünde bulundurularak verilir. Bu süre, en fazla beş yıla kadar uzatılabilir (İnfaz K, m. 108, f. 6).

Bu itibarla, **örgüt mensubu olup olmadığına bakmaksızın, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olan kişi**, cezanın infazının tamamlanmasından sonra işleyecek olan denetim süresi zarfında da **denetimli serbestlik tedbirine** tabi tutulacaktır (İnfaz K, m. 108, f. 4, 5, 6).

Terörle Mücadele Kanununun 17. maddesinde **özel bir tekerrür hükmüne** de yer verilmiştir.

765 sayılı Kanundan farklı olarak, yeni TCK’da tekerrür nedeniyle cezanın artırılması yoluna gidilmemektedir. Suç işlemeye tekerrür hali, kişinin diğer suçlara nazaran toplum açısından daha fazla tehlikeli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu itibarla tekerrür, TCK’da belirlenen sair hallerin yanı sıra, kişi hakkında hükmolunan hapis cezasının infazı sürecinde koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanması ile bağlantılı olarak dikkate alınacaktır.

Terörle Mücadele Kanununa göre;

“Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, hükümlerinin kesinleşme tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla salıverilmeden yararlanamazlar.” (m. 17, f. 3).

Bu özel tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için *iki koşulun* gerçekleşmesi gerekir.

Birinci koşul: Kişinin Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suçtan dolayı mahkum olması gerekir.

Bu düzenlemede, cezaya veya güvenlik tedbirine mahkumiyet arasında bir ayırım öngörülmemiştir. Kanımızca, buradaki mahkumiyeti **cezaya mahkumiyet** olarak anlamak gerekir ve dolayısıyla; örneğin TCK’nın 50. maddesine göre seçenek yaptırım olarak sadece güvenlik tedbirine mahkumiyet halinde, bu özel tekerrür hükmü uygulanmamalıdır.

Keza, söz konusu özel tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için, Kanunun bu düzenlemesi karşısında, önceden mahkum olunan cezanın hapis veya adli para cezası olması bir önem taşımamaktadır. Ancak, hapis veya adli para cezasına mahkumiyetin, **Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suçtan dolayı** verilmiş bir mahkumiyet olması gerekmektedir.

Bu özel tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için, TCK'nın düzenlemesinde olduğu gibi, daha önceki cezaya ilişkin mahkumiyet hükmünün **infaz edilmiş olması gerekmektedir.**

İkinci koşul: Önceki suçtan dolayı verilmiş olan mahkumiyet kararı kesinleştikten sonra, yine Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren yeni bir suçun işlenmiş olması ve bu suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmak gerekir.

Ancak, TCK'dan farklı olarak, önceki mahkumiyet hükmünün infazından itibaren ne kadar süre geçmiş olursa olsun, bu özel tekerrür hükmü uygulanabilecektir. Başka bir deyişle, bu özel tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren ikinci bir suçun önceki mahkumiyet hükmünün infazından itibaren belli bir süre zarfında işlenmiş olması önem taşımaktadır. Böylece, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar bakımından süresiz bir tekerrür sistemi benimsenmiştir.

Belirtilmelidir ki, mahkemenin, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren yeni bir suç işlemiş olması dolayısıyla hakkında kurduğu mahkumiyet hükmünde failin bu özel tekerrür hükmü gereği olarak koşullu salıverilmeden yararlanamayacağını açıkça belirtmesi gerekir. Bu sonuca, TCK'nın 58. maddesinin yedinci fıkrası hükmüne kıyasen ulaşmaktayız. Aksi takdirde, somut olayda bu özel tekerrür hükmünün uygulanıp uygulanamayacağını belirleme imkanı bulunmamaktadır.

Ekskurs 5. Kabahatlerde Tekerrür Sorunu

5326 s. Kabahatler Kanununa ilişkin Hükümet Tasarısının Genel Gerekçesinde “*tekerrür bakımından suçlarla kabahatler arasında önemli farklılıklar bulun*”duğu vurgulanarak, Tasarı metninde kabahatler bakımından özel tekerrür hükümlerine yer verilmişti (m. 22):

“Tekerrür

MADDE 22- (1) İdari para cezasına ilişkin karar verildikten sonra aynı kabahatin tekrar işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanır. Bir kabahati oluşturan farklı seçimlik hareketlerin işlenmesi halinde de, aynı kabahatin varlığı kabul edilir.

(2) Tekerrür halinde, idari para cezası yarı oranında artırılır.

(3) İdari para cezasının tamamen yerine getirilmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen kabahat açısından, önceki kabahat, tekerrüre esas teşkil etmez.”

Bu maddenin Hükümet Tasarısı gerekçesi şöyleydi:

“Madde metninde, kabahatlerde tekerrür düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, kabahatler açısından tekerrür hükümleri aynı kabahatin tekrar işlenmesi halinde uygulanabilir.

*Bir kabahate ilişkin idari para cezası verildikten sonra, **aynı kabahatin tekrar işlenmesi halinde**, tekrar işlenen kabahat dolayısıyla verilen idari para cezasının artırılması öngörülmüştür.*

Üçüncü fıkrafta, tekerrür hükümlerinin uygulanması bakımından bir süre sınırlaması getirilmiştir.”

Ancak bu madde, TBMM Adalet Komisyonunda söz konusu Kanuna ilişkin Tasarının görüşmeleri sırasında, “*kabahatlerde tekerrür hükmüne gerek görülmediğinden metinden çıkarılmıştır.*”⁴¹⁰

Tekerrür hükümlerinin uygulanabilirliği bakımından, işlenen kabahatler dolayısıyla verilen idari yaptırım kararlarına ilişkin olarak bir kayıt sisteminin oluşturulması, büyük bir önem taşımaktadır. Böyle bir kayıt sisteminin oluşturulmasındaki güçlük göz önünde bulundurularak, Kanun koyucu tarafından kabahatlerle ilgili olarak genel bir tekerrür düzenlemesinden sarfınazar edilmiştir.

Ancak, çeşitli kanunlarda kabahat olarak tanımlanan fiillerin kendi aralarında tekerrür dolayısıyla **idari para cezasının miktarının artırılmasına** veya **ilave idari yaptırımlar uygulanmasına imkan tanıyan özel tekerrür hükümlerine** yer verilmektedir. Çeşitli kanunlarda kabahatlere özgü özel tekerrür hükümlerine yer verilmesinin Kabahatler Kanununun sistemi ile çelişmediğini belirtmek isteriz.

Örneğin 5607 s. KMK’nın 8. maddesinde söz konusu Kanunda tanımlanan kabahatlerle ilgili olarak özel tekerrür hükümlerine yer verilmiştir:

“Tekerrür

MADDE 8– (1) Bu Kanundaki kabahatler dolayısıyla verilen idari para cezasına ilişkin karar kesinleştikten sonra tekrar kabahat işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanır.

(2) Tekerrür halinde, idari para cezası yarı oranında artırılır.

(3) İdari para cezasının tamamen yerine getirilmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen kabahat açısından, önceki kabahat, tekerrüre esas teşkil etmez.

(4) Tekerrüre esas alınacak idari para cezaları hakkındaki kayıtların, Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde tutulmasına ilişkin esas ve usûller yönetmelikle düzenlenir.”

5607 s. KMK’ya ilişkin Tasarı metninde bulunmayan bu madde, TBMM Adalet Komisyonunda, metne eklenmiştir. TBMM Adalet Komisyonunun 5.12.2006

⁴¹⁰ Türkiye Büyük Millet Meclis Adalet Komisyonu’nun Kabahatler Kanunu Tasarısına ilişkin 23.3.2005 tarihli ve Esas: 1/993, Karar: 72 sayılı Raporu, TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840, sh. 13.

tarihli ve Esas: (1/1240), (2/403), (2/644), Karar: 114 sayılı Raporunda, söz konusu maddenin **gerekçesi** şu şekilde açıklanmıştır:

“... Bu düzenlemeye göre, Tasarının 3'üncü maddesinde tanımlanan kabahatler dolayısıyla verilen idari para cezasına ilişkin karar kesinleştikten sonra tekrar kabahat işlenmesi halinde tekerrür dolayısıyla idari para cezası yarı oranında artırılacaktır. Tekerrür dolayısıyla idari para cezasının artırılabilmesi için, sonraki kabahatle tekerrüre esas oluşturan kabahatin aynı kabahat olması gerekmemektedir. Tekerrür dolayısıyla idari para cezasının artırılabilmesi için, her iki kabahatin de (5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda) tanımlanan kabahat olması yeterlidir. Keza, tekerrür dolayısıyla idari para cezasının artırılabilmesi için, tekerrüre esas oluşturan kabahatten dolayı verilen idari para cezasının yerine getirilmesi şart değildir. Ancak, sonradan işlenen kabahatin tekerrüre esas teşkil eden kabahatten dolayı verilen idari para cezası yerine getirildikten itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenmesi halinde, tekerrür dolayısıyla idari para cezası artırılmayacaktır. Yapılan düzenlemeye göre tekerrür olgusunun takip edilebilmesi için, (5607 s. KMK'da) tanımlanan kabahatlerin işlenmesi dolayısıyla verilen ve kesinleşen idari para cezalarının bir sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Her ne kadar bu para cezalarına karar vermeye kural olarak Cumhuriyet savcıları yetkili kılınmış ise de kesinleşen kararların kaydının Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde tutulması gerekecektir. Ancak, bu hususa ilişkin esas ve usulleri belirleyen bir yönetmeliğe ihtiyaç bulunmaktadır. ...”⁴¹¹.

XXII. Sınır Dışı Edilme

Yeni TCK'nın 59. maddesi hükmüne göre; “İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.”

Bu madde, 31.3.2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunla (m. 1) değiştirilmiştir. Değişiklikten önceki madde metni şu şekilde idi:

“(1) İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancının, cezasının infazından sonra derhâl sınır dışı edilmesine de hükmolunur.”

Bu maddenin gerekçesinde sınır dışı etmenin bir **güvenlik tedbiri** olduğu vurgulanmıştır.

⁴¹¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1275, sh. 14. Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sh. 45 vd.

5328 sayılı Kanunun TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında verilen önerge üzerine değiştirilen bu maddenin değişiklik önergesindeki **gerekçesi** şu şekildedir:

“Yabancıнын sınır dışı edilmesi konusunda karşılaşılan güçlükler nedeniyle kanun metninde sınır dışı edebilme hususunda ilgili kişinin durumunun değerlendirilebilmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığına takdir yetkisinin tanınmasının daha yerinde olacağı düşüncesiyle işbu önerge verilmiştir.”

Söz konusu madde hükmü, Emniyet Genel Müdürlüğünün itirazları üzerine değiştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, 5328 s. Kanunun TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında sınır dışı etme hususunda kanuni bir zorunluluk getirilmesinin, uygulama bakımından büyük sıkıntılara neden olacağı yönünde endişeler dile getirmişlerdir. Bu endişelere dayalı olarak madde metni değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikte, Türk vatandaşı olmayan hükümlünün, cezasının infazı tamamlandıktan sonra, sınır dışı edilip edilmemesi hususu tamamen İçişleri Bakanlığının takdirine bırakılmıştır. **Böylece, sınır dışı edilme, bir ceza hukuku yaptırımı olarak güvenlik tedbiri olmaktan çıkıp, bir idari tedbir mahiyetine kavuşmuştur.**

Söz konusu madde metninde 17.6.2021 tarihli ve 7238 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre, cezasını infaz kurumunda çekmekte olan yabancı hükümlü, “denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına veya koşullu salıverilmesine karar verildikten sonra” sınır dışı edilebilecektir.

XXIII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

Anayasa’nın 38’inci maddesinde hüküm altına alınan “ceza sorumluluğu şahsidir” kuralı (f. 6), yeni TCK’nın 20’nci maddesinde ifade edilmiştir.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralı ile kusursuz ceza olmaz kuralı, birbirinden ayrı hususlara ilişkin iki kural olmakla birlikte; bunlar arasında yakın bir ilişki mevcuttur.

Yeni TCK’nın 20’nci maddesi altında yapılan açıklamalarda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralı gereği olarak; tüzel kişinin organ veya temsilcinin fiil ve tasarrufları dolayısıyla, tüzel kişi hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz.

Organ veya temsilcisinin fiil ve tasarrufları dolayısıyla tüzel kişilik lehine örneğin haksız bir kazanç elde edilmiş olabilir. Bu durum dahi, tüzel kişinin suç faili olabileceği ve dolayısıyla, ceza sorumluluğunun olduğu yönündeki düşünceye haklılık kazandırmaz.

Yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere, tüzel kişinin fiil ehliyeti mevcut değildir⁴¹². Tüzel kişi, belli bir amaca yönelik, gaî (final) olarak hareket edemez. Bu

⁴¹² BLAUTH, 14, 33; ROXIN, Claus: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, Bd. I, *Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre*, München, 1992, § 8, kn. 55, 56; WESSELS, Johannes: *Strafrecht, Allgeme-*

nedenle, tüzel kişiyi normun muhatabı (ve dolayısıyla, yükümlüsü) olarak telâkki etmek mümkün değildir⁴¹³. Çünkü, ancak insan, davranışlarını belli bir gayeye matuf olarak yönlendirebilir. Yani, yönlendirici irade kabiliyetine sahip olan tek yaratık, insandır. Suç olarak telâkki edilen muayyen haksızlığın esasını teşkil eden fiili, yani gaî hareketi ancak insan gerçekleştirebileceğine göre; tüzel kişinin suç faili olabilmesi hiçbir surette düşünülemez.

Tüzel kişinin fiil ehliyeti olmadığına göre, kusur ehliyetine de sahip olmadığını öncelikle söyleyebiliriz⁴¹⁴. Çünkü, kusur ehliyetine sahip olabilmek için, önce fiil ehliyetine sahip olmak gerekir. Haksızlık olarak değerlendirilen bir fiil dolayısıyla bu fiil failinin muaheze edilmesi gerektiği konusundaki yargıyı ifade eden kusurun⁴¹⁵ bir tüzel kişiye atfı hiçbir surette mümkün değildir. Bu nedenlerle, *tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır*⁴¹⁶.

Ceza, bir insanın işlemiş bulunduğu bir haksızlıktan dolayı muaheze edilmesi gerektiği hususundaki yargının somutlaşmasıdır, maddi bir muhteva kazanmasıdır⁴¹⁷. İşlediği haksızlık dolayısıyla kişinin muaheze edilmesi gerektiği hususundaki yargıyla ceza arasındaki bu ilişki, cezanın *kefarete* teşkil ettiği hususundaki anlayışın bir sonucudur⁴¹⁸. Fakat, cezanın kefarete özelliğinin yanı sıra, aynı zamanda bir teleolojik yönü de mevcuttur. Ceza, sadece kefarete özelliği taşımamaktadır; aynı zamanda, toplumda hakim olan hukuki değerlerin etkin bir şekilde korunması amacına hizmet eden bir araç durumundadır⁴¹⁹. Cezanın *önleme fonksiyonu* olarak telâkki edilen bu halde de, genel ve özel önleme olmak üzere, iki amaç güdülmektedir⁴²⁰.

Dikkat edilmelidir ki; cezanın gerek kefarete özelliği, gerek önleme etkisi, ancak *gerçek kişiler*, yani *insanlar* açısından söz konusudur. Bizzat tüzel kişi açısından cezanın ne kefarete özelliğinden ne de önleme etkisinden bahsetmek mümkündür.

iner Teil, 19. Auflage, Heidelberg, 1988, sh. 25; ÖNDER, Genel Hükümler II, 42; ayrıca bkz. SE-ROZAN, Rona: *Tüzel Kişiler*, İstanbul, 1990, sh. 21. Ancak, günümüz Ceza Hukukçuları arasında dahi, tüzel kişinin fiil ehliyetinin var olduğunu savunanlar mevcuttur: BAUMANN, Jürgen/WEBER, Ulrich: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 9. Auflage, Bielefeld, 1985, sh. 196. Medenî Hukuk sahasında tüzel kişilere müteallik olarak *hukuki muamele ehliyetinden* bahsedilebilir. Tüzel kişi adına bu ehliyet Kanuna ve kuruluş belgelerine uygun *organ(uzuv)lar* sahiptirler.

⁴¹³ BLAUTH, 33; ÖZGENÇ, Türk Devletleri ..., sh. 417.

⁴¹⁴ ESER, Albin: Schönke/Schröder(23), § 75, kn. 8. Aynı şekilde ÖZTAN, Bilge: *Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk*, Ankara, 1970, sh. 135.

⁴¹⁵ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh. 78 vd.

⁴¹⁶ CRAMER, Peter: Schönke/Schröder(23), Vorbem. vor §§ 13 ff., kn. 99; BLAUTH, sh. 9.

⁴¹⁷ Arm. KAUFMANN, sh. 228, 229; JESCHECK, Lb.(4), sh. 48.

⁴¹⁸ Arm. KAUFMANN, sh. 229. Cezanın kefarete teşkil ettiği hususundaki görüşler için bkz. MAURACH/ZIPF I, sh. 64 vd.; JESCHECK, Lb.(4), sh. 62/63.

⁴¹⁹ Arm. KAUFMANN, sh. 229.

⁴²⁰ JESCHECK, Lb.(4), sh. 59 vd.; MAURACH/ZIPF I, sh. 80 vd.

Organ veya temsilcilerin gerçekleştirdikleri suç teşkil eden fiillerden dolayı şayet tüzel kişi hakkında ceza yaptırımına hükmedilirse; bu suretle tüzel kişinin bütün üyeleri/ortakları cezalandırılmış ve ceza hukukunun temel prensiplerinden olan *cezaî sorumluluğun şahsiliği* kuralı ihlâl edilmiş olur. Tüzel kişinin organ veya temsilcilerinin kanunla kendilerine yüklenen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri, yani suç teşkil eden bir haksızlığı gerçekleştirmeleri halinde, şayet "tüzel kişinin kendisi ceza"landırılırsa, elbette ki söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinde hiç kusuru olmayan üyeler/ortaklar da cezalandırılmış olacaklardır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, adli para cezasının tahsili açısından sağladığı kolaylık, tüzel kişilerin de ceza sorumluluğu olduğu sonucuna bizi götüremez. Bu gerekçe, Kanunun 20'nci maddesinin **gerekçesinde** açık bir şekilde vurgulanmıştır:

«Tüzel kişiler için ancak idari yaptırım niteliğinde “para cezası” öngörülebilir. Çünkü, idari yaptırımlarla, ceza yaptırımları arasında neden, amaç ve sonuçları bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, şirket niteliğindeki bir tüzel kişinin faaliyeti ile ilgili olarak doğan vergi borcunun zamanında ve tam olarak ödenmemesi dolayısıyla, tüzel kişi hakkında da “para cezası” verilebilmektedir. Ancak, bu yaptırımın asıl amacı, verginin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmemesi dolayısıyla kamu maliyesinin uğradığı zararın giderilmesi ve vergi düzeninin etkinliğinin sağlanmasıdır. Bu tür yaptırımların bir ceza hukuku yaptırımı olmadığı açıktır. Vergi borcunun gerçeğe uygun bir şekilde doğmasının önüne geçebilmek amacıyla sahte belge düzenlenmiş olması durumunda ayrıca bu sahteciliği gerçekleştiren gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımına hükmedilebilecektir. Bu durumda bile tüzel kişi hakkında verilen “para cezası”, bir idari yaptırım olma özelliğini korur.»

Ancak, bu açıklamalardan, işlenen suç dolayısıyla özel hukuk tüzel kişileri hakkında **güvenlik tedbiri** niteliğinde yaptırımlara da hükmedilemeyeceği sonucu çıkarılamaz⁴²¹.

Bu itibarla, yeni TCK'da işlenen suç dolayısıyla tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanabileceği kabul edilmiştir (m. 60)⁴²².

Madde metninde kabul edilen birinci güvenlik tedbiri, **faaliyet izninin iptalidir** (f. 1). Faaliyet izninin iptali için;

a) **kasıtlı bir suçun** işlenmiş olması,

⁴²¹ Özbek'e göre, tüzel kişilere güvenlik tedbiri yaptırımı uygulanabiliyorsa, suç işleyebilecekleri de kabul edilmiş olmaktadır: ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 3. bası, sh.270.

⁴²² İsviçre Ceza Kanununa göre, bir özel hukuk tüzel kişisi adına görev yapan kişinin görevi ile bağlantılı olarak işlediği suçtan dolayı tüzel kişi hakkında yaptırım uygulanabilmesi için, bu tüzel kişi bünyesinde *“bu gibi suiistimallerin önüne geçmeye yönelik gerekli ve beklenebilir tedbirlerin alınması gerekir”* (m. 100quanter, f. 2).

- b) suçun tüzel kişinin **organ veya temsilcisi** sıfatını taşıyan **kişilerin iştirakiyle** işlenmesi ve bu kişiler hakkında işledikleri suç nedeniyle **mahkumiyet** kararı verilmiş olması,
- c) suçun, **faaliyet izninin sağladığı yetki kötüye kullanılmak suretiyle** işlenmesi,
- d) suçun işlenmesiyle, **tüzel kişinin yararına bir kazanç** elde edilmiş olması, gerekmektedir.

Dikkat edilmelidir ki, faaliyet izninin iptali, ilgili tüzel kişinin varlığını sona erdirmemektedir. Tüzel kişi varlığın devam ettirmekle birlikte, iznin konusuyla ilgili olarak faaliyette bulunması engellenmektedir. Örneğin, bankacılık faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun işlenmesi halinde, 5411 s. *Bankacılık Kanununun* 10. (yürürlükten kaldırılan 4389 s. *Bankalar Kanununun* 7.) maddesine göre verilen faaliyet izninin iptaline mahkemece hükmedilebilir.

Söz konusu 60. madde metninde ayrıca, tüzel kişiler hakkında Kanunun gerek **eşya müsadere**sine (m. 54) gerek **kazanç müsadere**sine (m. 55) ilişkin hükümlerinin uygulanabileceği kabul edilmiştir. Ancak, belirtmek gerekir ki, her iki müsadereye ilişkin hükümlerin tüzel kişi ile ilgili olarak uygulanabilmesi için, suçun tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, bir suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmesi hususu sadece TCK’da düzenlenmiş değildir⁴²³.

Örneğin, belirli nitelikteki suçların ve hatta esasen suç oluşturmayan ve fakat yasaklanmış bazı fiillerin bir siyasi partinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi, gerek Anayasa’da (m. 68, 69), gerek 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda (m. 78 vd.), siyasi parti kapatma sebebi olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar **siyasi parti ile ilgili kapatma kararını**, kapatma sebebini suç teşkil eden fiillerin oluşturması halinde, işlenen suçlardan dolayı yargılama yapmakla görevli ceza mahkemesi değil, Anayasa Mahkemesi vermekte ise de; bu karar niteliği gereği olarak bir **güvenlik tedbiridir**⁴²⁴.

⁴²³ Örneğin 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun.”Deniz taşıtları” başlıklı 7. maddesi ile ilgili olarak TBMM Adalet Komisyonunun 5.12.2006 tarihli ve Esas: (1/1240), (2/403), (2/644), Karar: 114 sayılı Raporunda şu açıklamalara yer verilmiştir: “... **Geminin donatanının veya acente sahibinin tüzel kişi olması halinde; bunların, ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralını güvence altına alan Anayasanın 38. maddesinin gereği olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun sistemine göre, cezalandırılması mümkün değildir. Bu sistemde ceza yaptırımı sadece gerçek kişiler hakkında öngörülmüştür. Ancak, geminin donatanının veya acente sahibinin gerçek kişi olması ve de bu kişinin suçun işlenmesine iştirak etmesi halinde Türk Ceza Kanununun iştirake ilişkin hükümlerine göre işlenen suçtan dolayı sorumlu tutulacağı hususunda kuşku yoktur.**” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1275, sh. 14; Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sh. 43).

⁴²⁴ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Reha Poroy’a Armağan, sh.319 vd.; ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku(3), sh. 97 vd.

Aynı değerlendirme, 17.7.2004 tarihli ve 5231 sayılı **Dernekler Kanunundaki** kapatmaya ilişkin hükümler açısından da geçerlidir.

Tüzel kişi, suç faili olamamakla birlikte, bir suç tüzel kişinin yararına olarak veya faaliyeti çerçevesinde işlenebilmektedir. Bir suçun tüzel kişinin yararına olarak veya faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bu tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilmektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu gibi durumlarda suçun faili tüzel kişi değil, tüzel kişinin organlarında görev yapan, tüzel kişinin temsilcisi sıfatını taşıyan veya tüzel kişinin faaliyetleri çerçevesinde herhangi bir şekilde görevlendirilmiş olan bir **gerçek kişidir**.

Keza, yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere, belirli suçların tüzel kişinin yararına olarak işlenmiş olması halinde, ilgili tüzel kişi hakkında **idari para cezasına hükmedilebilecektir** (5326 s. Kabahatler Kanunu, m. 43/A).

XXIV. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Güvenlik Tedbirleri

TCK dışındaki diğer kanunlarda düzenlenen güvenlik tedbirlerine örnek olarak, 14.12.2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenen “**çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı**” gösterilebilir.

5941 sayılı Çek Kanununda çekin karşılıksız çıkması **suç** olarak tanımlanmıştı (m. 5, f. 1)⁴²⁵. Ancak, söz konusu maddenin **31.1.2012** tarihli ve **6273** sayılı Kanunla değiştirilen birinci fıkrasında, **çekin karşılığının kanuni ibraz süresi içinde ibrazında ilgili banka hesabında bulundurulmaması** suç olmaktan çıkarılarak **kabahate dönüştürülmüştü**⁴²⁶. Söz konusu değişiklikten önceki kanuni düzenlemeye göre, çekin karşılıksız çıkması halinde **güvenlik tedbiri** olarak **çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı** kararı verilebilmekte idi. Yapılan değişiklikle, çekin karşılıksız çıkması halinde uygulanan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı artık **idari tedbire** dönüşmüştü.

Fakat bilahare, 5941 sayılı Kanunda **15.7.2016** tarihli ve **6728** sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, **çekin karşılığının kanuni ibraz süresi içinde ibrazında ilgili banka hesabında bulundurulmaması yeniden adli para cezasını** gerektiren bir **suç** olarak tanımlanmıştır (m. 5). Bu düzenlemeye göre, söz konusu ceza davasının görüleceği mahkeme, **icra mahkemesi** olacaktır. Söz konusu ceza davası Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen iddianame ile değil, **hâmilin icra mahkemesine yapacağı şikâyet üzerine**, başka herhangi bir işleme gerek olmadan, açılmış olacaktır. Mahkeme, bu durumda, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak çeki düzenleyen ve çek hesabı sahibi kişi hakkında **güvenlik tedbiri** olarak **çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı** kararı verecektir.

⁴²⁵ Söz konusu suç tanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Çek Kanunu*, 4. bası, Ankara, Ekim 2010, sh. 57 vd.

⁴²⁶ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: *Çek Kanunu*, 5. bası, Ankara, Şubat 2012, sh. 64 vd.

Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına, dava sürecinde de **koruma tedbiri** olarak da karar verebilecektir.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, bu suçun failiyle sınırlı olarak verilmemektedir. Bu karar,

- a) karşılıksız çıkan **çeki düzenleyen**,
- b) adına karşılıksız çek düzenlenen, yani **çek hesabı sahibi**,
- c) kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, **çekin karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan**,
kişi hakkında verilebilir.

Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu güvenlik tedbirine özel hukuk **tüzel kişisi** hakkında da hükmedilebilmektedir. Bu durumda çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, çek hesabı sahibi **tüzel kişinin yanı sıra**, bu tüzel kişinin yetkilisi sıfatıyla çeki düzenleyen veya kanunî ibraz süresi içinde ibrazında çekin karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olmasına rağmen bulundurmayan **gerçek kişi** hakkında da verilebilir.

Çeki karşılıksız çıkan çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilebilmesi için, bu tüzel kişinin yetkilisi olan gerçek kişi hakkında adli para cezasına hükmedilmiş olması şart değildir. Tüzel kişinin yetkilisi olan gerçek kişi soruşturma ve kovuşturma evresinde ölmüş olabilir. Bu durumda, fail hakkında adli para cezasına hükmedilememekle birlikte, çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilebilecektir.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tabi tutulan **her bir çekle ilgili olarak ayrı ayrı** verilir.

Keza, 31.3.2011 tarihli ve 6222 sayılı “**Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun**” hükümlerine göre (m. 18), belirli suçlardan dolayı yapılan yargılama sonucunda kişiler hakkında mahkemece **güvenlik tedbiri** olarak **spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirine** hükmedilebilecektir.

Seyirden yasaklama güvenlik tedbirine, 6222 s. Kanunda tanımlanan veya bu Kanunun yollamada bulunduğu diğer kanunlarda tanımlanan suçlarla ilgili olarak hükmedilebilir.

Bu suçlardan herhangi birinin işlenmesi dolayısıyla yapılan yargılama sonucunda suçun işlendiğinin sabit görülmesi halinde mahkemece kurulacak olan hükmünde sanıklar hakkında güvenlik tedbiri olarak **spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirine hükmedilecektir**.

Bu güvenlik tedbirine cezanın yanı sıra hükmedilecektir. Ancak, örneğin akıl hastası veya yaş küçüğü olan sanığın kusur yeteneğinin bulunmaması dolayısıyla-

la hakkında cezaya hükmedilmese bile, güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirine hükmedilebilecektir. Bu itibarla, söz konusu güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için cezaya mahkumiyet şart değildir.

Seyirden yasaklama güvenlik tedbirinin infazına hükmün kesinleşmesiyle derhal başlanır. Söz konusu güvenlik tedbirinin infazı, cezanın infazının tamamlanmasından itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer.

Kişi hakkında hükmolunan cezanın **hapis veya adli para cezası** olması, seyirden yasaklanma güvenlik tedbirine hükmedilmesi bakımından bir önem taşımamaktadır.

Kişi hakkında hükmedilen **hapis cezasının ertelenmesi halinde** de, seyirden yasaklanma güvenlik tedbirine hükmedilecektir (m. 18, f. 6). Bu durumda seyirden yasaklanma güvenlik tedbirinin infazına, **hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süreyle** devam olunur. Dikkat edilmelidir ki, hapis cezasının ertelenmesi halinde seyirden yasaklama güvenlik tedbirinin uygulama süresi denetim süresi ile ilişkilendirilmemiştir. Kanaatimizce, Kanunda yapılacak bir değişiklikte, denetim süresi zarfında bu tedbirin uygulanmasına devam edilmesini sağlamak gerekir.

Keza, kişi hakkında hükmedilen **hapis cezasının TCK'nın 50. maddesindeki seçenek yaptırımlara çevrilmesi halinde**, seyirden yasaklanma güvenlik tedbirine hükmedilecektir (m. 18, f. 6). Kısa süreli hapis cezasının bu seçenek yaptırımlardan **adli para cezasına** çevrilmesi halinde, seyirden yasaklanma güvenlik tedbirinin infazı **adli para cezasının infazının tamamlanmasından itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer**. Buna karşılık, kısa süreli hapis cezasının bu seçenek yaptırımlardan **tedbire** çevrilmesi halinde, seyirden yasaklanma güvenlik tedbirinin infazı **hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer**.

Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilir (m. 18, f. 1).

Güvenlik tedbiri olarak hükmedilen spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararları, kesinleştikleri takdirde, 5352 sayılı Kanun hükümlerine göre **adli sicile kaydedilir** (m. 18, f. 1, son cümle). Keza, bu kararlara ilişkin bilgiler, ayrıca “*Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan bu amaca özgü elektronik bilgi bankasına derhal kaydedilir. Bu bilgi bankasına spor kulüplerinin ve federasyonların erişimi sağlanır. Yasaklanan kişilere ilişkin bilgiler, ilgili spor kulüplerine ve yurt dışında yapılacak müsabaka öncesinde müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirilir.*” (m. 18, f. 4).

“Bu Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici

olamaz; spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev yapamaz.” (m. 18, f. 10)^{427, 428}.

⁴²⁷ Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZTÜRK, Bahri: *Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Çare Olarak Seyirden Yasaklanma*, in: Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu, Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi yayını; Editörler: Cumhur Şahin, İzzet Özgenç ve İlhan Üzülmüş, 2. bası, Ankara, Ocak 2012, sh. 33 vd.; ÖZGENÇ, İzzet: *Değerlendirme ve Sonuç*, aynı eser, sh. 111 vd.

⁴²⁸ Seyirden yasaklamaya, **koruma tedbiri** olarak ve hatta **idari tedbir** olarak da karar verilebilmektedir:

a) Koruma Tedbiri Olarak Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama

Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verilebilecek olan suçlarla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma devam ederken bu yasak, **şüpheli** ve **sanıklar** hakkında koruma tedbiri olarak uygulanmaktadır. Yukarıda liste halinde vermiş bulunduğumuz “*suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilir.*” (m. 18, f. 3).

Dikkat edilmelidir ki, şüpheli veya sanık hakkında koruma tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin uygulanabilmesi için, **hakim veya C. savcısının karar almasına gerek bulunmamaktadır**. Kişi hakkında belirli suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde, bu tedbirin uygulanmasına **kanun hükmü gereği** olarak başlanır. Ancak, soruşturma evresinde C. savcısı, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından bu **tedbirin kaldırılmasına karar** verilebilir.

Şüpheli veya sanık hakkında **koruma tedbiri** olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama uygulamasının başlamasıyla birlikte, hakkında tedbir uygulaması yapılan kişiye ilişkin kimlik bilgileri, “*Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan bu amaca özgü elektronik bilgi bankasına derhal kaydedilir. Bu bilgi bankasına spor kulüplerinin ve federasyonların erişimi sağlanır. Yasaklanan kişilere ilişkin bilgiler, ilgili spor kulüplerine ve yurt dışında yapılacak müsabaka öncesinde müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirilir.*” (m. 18, f. 4).

Şüpheli veya sanık hakkında **koruma tedbiri** olarak **spor müsabakalarını seyirden yasaklama uygulaması, soruşturma ve kovuşturma süresince devam eder**. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, soruşturma evresinde C. savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu **tedbirin kaldırılmasına karar** verilebilir.

Soruşturma evresi sonunda C. savcısı **kamu davasının açılmasının ertelenmesine** karar vermiş olabilir. Bu durumda, **kararın kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süreyle** spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin uygulanmasına devam edilir (m. 18, f. 6). Bu nedenle, yukarıda liste halinde verilen suçlardan herhangi biri ile ilgili olarak şüpheli hakkında verilen kamu davasının ertelenmesi kararı kesinleştikten sonra, gerekli bilgilerin bilgi bankasına işlenmesi amacıyla, bir örneğinin C. savcısı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

Önödeme ile de soruşturma sonuçlandırılmış olabilir. Bu durumda şüpheli tarafından “*önödeme bulunulduğu tarihten itibaren, bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin uygulanmasına devam edilir.*” (m. 18, f. 6). Bu nedenle, yukarıda liste halinde verilen suçlardan biri ile ilgili olarak verilen önödeme emri üzerine şüpheli tarafından önödeme bulunulması halinde, gerekli bilgilerin bilgi bankasına işlenmesi amacıyla, durumun C. savcısı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

Kovuşturma evresinde mahkeme tarafından sanık hakkında **hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına** karar vermiş olabilir. Bu durumda, **kararın kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süreyle** spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin uygulanmasına devam edilir (m. 18, f. 6). Bu nedenle, yukarıda liste halinde verilen suçlardan herhangi biri ile ilgili olarak sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kesinleştikten sonra,

XXV. Denetimli Serbestlik Tedbiri

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni mevzuatımızda denetimli serbestlik tedbiri, müstakil bir yaptırım türü olarak öngörülmemiştir. Bu bakımdan, denetimli serbestlik tedbiri, hapis cezasının veya belirli güvenlik tedbirlerinin infazı sürecinde bu yaptırımları tamamlayan bir kurum niteliği taşımaktadır (*Denetimli serbestlik tedbirinin tamamlayıcı özelliği*)⁴²⁹. Bu bağlamda denetimli serbestlik tedbirinin,

gerekli bilgilerin bilgi bankasına işlenmesi amacıyla, bir örneğinin mahkeme tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

“Koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri;

a) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmesi,

b) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi,

c) Sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi,

halinde derhal **kaldırılır.**” (m. 18, f. 5).

Yukarıda liste halinde verilen suçlardan herhangi biri ile ilgili olarak yapılan soruşturmada C. savcısı tarafından, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde, karar kesinleştikten sonra, gerekli bilgilerin bilgi bankasına işlenmesi amacıyla, bir örneğinin Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

Keza, yukarıda liste halinde verilen suçlardan herhangi biri ile ilgili olarak yapılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, karar kesinleştikten sonra, gerekli bilgilerin bilgi bankasına işlenmesi amacıyla, bir örneğinin C. savcısı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

Söz konusu suçlardan dolayı yapılan yargılamada mahkeme tarafından sanığın beraatine veya davanın düşmesine hükmedilmesi halinde, karar kesinleştikten sonra, gerekli bilgilerin bilgi bankasına işlenmesi amacıyla, bir örneğinin mahkeme tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

b) İdari Tedbir Olarak Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama

Kanuna göre, “Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanına alınmaz. Bu şekilde spor alanlarına giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor kullanılarak dışarı çıkarılır ve bu madde hükümlerine göre bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanır.” (m. 18, f. 7).

Bu durumda ilgili kişi hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirine karar vermeye **Cumhuriyet savcısı** yetkilidir (m. 23, f. 3). Bu itibarla, fiil suç oluşturmaya bile, kişi **idari tedbir** olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanabilmektedir. Cumhuriyet savcısının bu konuda verdiği karara karşı **Kabahatler Kanunu** hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.

Güvenlik tedbiri, koruma tedbiri veya idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, “yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.” (m. 18, f. 8). Bu “yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi, yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.” (m. 18, f. 9). Dikkat edilmelidir ki, ayrıca bu suçtan dolayı da kişi koruma veya güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanabilecektir.

(Bu hususlarda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, *Değerlendirme ve Sonuç*, in: adı geçen eser, sh. 129 vd.)

⁴²⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. NURSAL, Necati/ATAÇ, Selcen: *Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi (Probation)*, Ankara, 2006.; *Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri El Kitabı* (Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı yayını), Ankara 2006.

a) hükmolunan hapis cezasının infazı sürecinde ve hatta, infazı tamamlandıktan sonra belirli bir süreyle,

b) hükmolunan güvenlik tedbirinin infazı sürecinde,

hükümlünün topluma intibak edebilmesine ve kendisine yüklenen yükümlülüklerin gereklerini yerine getirebilmesine katkı sağlamak yönünde bir fonksiyon görmesi hedeflenmektedir.

Keza, sanıkla ilgili olarak hakkında bir cezaya hükmedilmeden önce veya kurulmuş olan hüküm henüz açıklanmadan önce de, denetimli serbestlik kararı verilebilmektedir. Bu durumda da, denetimli serbestlik tedbiriyle sanığın topluma intibak edebilmesine ve kendisine yüklenen yükümlülüklerin gereklerini yerine getirebilmesine katkı sağlamak yönünde bir fonksiyon görmesi hedeflenmektedir.

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni mevzuatımızda denetimli serbestlik tedbirine sadece mahkemece karar verilebilir. Bu itibarla, örneğin C. savcısı tarafından denetimli serbestlik kararı verilemez.

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni mevzuatımızda denetimli serbestlik tedbirinin uygulanabileceği halleri şu şekilde tasrih edebiliriz:

I. Sanık hakkında cezaya hükmedilmeden önce denetimli serbestlik tedbiri kararı verilebilir.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile ilgili olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık hakkında şayet cezaya hükmolunmayacaksa, mahkemece denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilir (TCK, m. 221, f. 5)⁴³⁰⁴³¹.

II. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile birlikte denetimli serbestlik tedbiri kararı verilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olma-

⁴³⁰ Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasına rağmen sanık hakkında cezaya hükmedilmediği halinde, ayrıca denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü, bu hükümlünün örgüt mensubu kişi olması itibarıyla hakkında TCK'nın 58. maddesi (f. 9) ve İnfaz Kanununun 108. maddesi (f. 4, 6) hükümlerine istinaden denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır. Nitekim, TCK'nın 221. maddesinin gerekçesinde denetimli serbestlik tedbirinin etkin pişmanlık dolayısıyla kişinin serbest bırakılması haline özgü olarak kullanılabileceğine işaret edilmiştir (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 616 vd.).

⁴³¹ Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında verilen denetimli serbestlik tedbiri; örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan, gönüllü olarak örgütten ayrılan veya teslim olan ya da yakalanan, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlayan kurucu, yönetici ve örgüt üyeleri hakkında mahkemelerce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan hükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirmesini öngören tedbirlerdir (Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği, m. 73, f. 1).

mak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilebilir. (CMK, m. 231, f. 8).

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kapsamında hükmedilen denetimli serbestlik tedbirleri ve bu tedbirlerin yerine getirilmesi usulü Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 58. ila 61. maddelerinde düzenlenmiştir.

III. Kısa süreli hapis cezası yerine seçenak yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirlerinin infazı sürecinde hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Kısa süreli hapis cezası yerine hükmedilen seçenak yaptırımlardan, örneğin belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma tedbirinin uygulanabilmesi için, bu tedbir süresince kişi denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulur (TCK, m. 50, f. 1, bent a-e; İnfaz K, m. 105).

IV. Hükmolunan hapis cezasının ertelenmesi halinde, denetim süresi zarfında hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Hapis cezasının ertelenmesi halinde, denetim süresi zarfında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanabilmesi için mahkemece ayrıca karar vermeye gerek bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, cezası ertelenen kişi hakkında denetim süresi zarfında kural olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanır (TCK, m. 51, f. 4, 5). Ancak mahkeme, "*hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak,*" hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamasına karar verebilir (TCK, m. 51, f. 6).

Hapis cezasının ertelenen kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi halinde söz konusu tedbirlerin ne şekilde yerine getirileceği Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 66 ila 70. maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

V. Hükmolunan hapis cezasının infazı sürecinde koşullu salıverilme öncesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz kurumundan çıkarılır.

İnfaz Kanununa 5.4.2012 tarihli ve 6291 sayılı Kanunla eklenen 105/A maddesi hükümlerine göre, hapis cezasının infazı sürecinde, cezasını infaz kurumunda çekmekte olan hükümlü, hakkında henüz koşullu salıverilme hükümleri uygulanmadan önce, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz kurumundan dışarı çıkarılabilmektedir.

Hapis cezasının infazı sürecinde koşullu salıverilme öncesinde denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi halinde, söz konusu tedbirlerin ne şekilde yerine getirileceği Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 78 ve devamı maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

VI. Hükmolunan hapis cezasının infazı sürecinde koşullu salıverilmeden yararlanılması halinde, denetim süresi zarfında hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Koşullu salıverilme halinde, denetim süresi zarfında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanabilmesi için mahkemece ayrıca karar vermeye gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, koşullu salıverilen hükümlü hakkında denetim süresi zarfında kural olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Ancak mahkeme, “*koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini ve topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulundurarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine karar verebileceği gibi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde kaldırabilir.*” (İnfaz K, m. 107, f. 10)⁴³².

Koşullu salıverilme halinde, denetim süresi zarfında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi halinde, söz konusu tedbirlerin neler olduğu ve nasıl uygulacağına ilişkin düzenlemeler Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 89 ve devamı maddelerinde yer almaktadır.

VII. Cezanın infazı tamamlandıktan sonra da denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilebilir.

Mükerrirler, itiyadî suçlular, suçu meslek edinen kişiler ve örgüt mensubu suçlular hakkında cezanın infazından sonra da denetimli serbestlik tedbiri uygulanır (İnfaz K, m. 108, f. 4-6). Hapis cezasının infazının tamamlanmasından sonra uygulanacak olan denetimli serbestlik tedbirine, koşullu salıverilmeye karar veren mahkeme tarafından karar verilmesi gerekir.

⁴³² 5275 s. İnfaz Kanununa 5.4.2012 tarihli ve 6291 sayılı Kanunla eklenen “*Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı*” başlıklı 105/A maddesi ile, hapis cezasına mahkum olup da belirli şartları taşıyan hükümlülerin cezanın infazı sürecinde koşullu salıverilme için infaz kurumunda çekmeleri gereken asgari süre dolmadan da “*denetimli serbestlik tedbiri*”ne tabi tutulmak üzere serbest bırakılabilmelerine imkan tanınmıştır. Bilahare 2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun geçici 3. maddesinin ikinci fıkrası ile İnfaz Kanununun söz konusu maddesinin uygulama alanı genişletilmiştir. “*Denetimli serbestlik tedbiri*” müessesesiyle ilişkilendirilerek yapılmış olan bu düzenleme, hapis cezasının infazı bakımından **cezanın caydırıcılık etkisini ortadan kaldırarak sonuç doğuracak bir mahiyet taşımaktadır**. Bu itibarla, infaz kurumlarındaki hükümlü sayısının azaltılması amacıyla yapılmış olan bu düzenlemenin ceza siyaseti bakımından doğru olmadığını düşünmekteyiz.

§26. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Cezanın belirlenmesinde izlenecek usul, suç teorisinde suçun yapısı irdelenirken izlenen usulle paralellik arz etmektedir.

Ceza belirlenirken önce, işlenen fiilin **haksızlık içeriği**; bilahare, gerçekleştirilen haksızlık dolayısıyla kişinin **kusuru**, kusurluluk durumu göz önünde bulundurulur.

Cezanın belirlenmesi sürecinde kişinin kusurunun göz önünde bulundurulması, aynı zamanda cezanın bireyselleştirilmesi enstrümanlarından birini oluşturmaktadır.

İşlenen suçun ifade ettiği haksızlık içeriği bakımından cezanın belirlenmesi sürecinde, önce **temel ceza** belirlenmektedir⁴³³.

Bazı suçlar bakımından temel cezanın belirlenmesinde bir sorunla karşılaşılmaz. Çünkü, ilgili suçun kanunî tarifinde tek ve maktu bir ceza öngörülmüştür. Temel şekli bakımından müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının öngörüldüğü suçlar, bu hususta örnek olarak gösterilebilir.

Kanunî tarifinde hapis cezasının alt ve üst sınırı belirlenen suçlarda, temel ceza bu iki sınır arasında tayin edilecektir. Alt ve üst sınırlar arasında ceza belirlenirken, 61'inci maddenin birinci fıkrasındaki yedi ölçüt göz önünde bulundurulacaktır. Ancak, belirtmek gerekir ki; *“birinci fıkrafta belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hâllerde, bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz.”* (m. 61, f. 3). Bu durumda, söz konusu unsurlar, 61'inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen usul çerçevesinde dikkate alınacaklardır.

Temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak ölçütler, 61'inci maddenin birinci fıkrasında gösterilmiştir. Bu ölçütlerin işlenen suçun **haksızlık içeriği** konusunda etkili olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir⁴³⁴. Hukuka

⁴³³ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÜZÜLMEZ, İlhan: *Yeni Ceza Kanunu'nun Sisteminde Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi*, in: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Erzincan ÜHFD), cilt X, sayı 3-4, yıl 2006, sh. 203 vd.

⁴³⁴ “Yasa koyucu, cezaların kişiselleştirilmesinin sağlanması bakımından hâkime, olayın özelliği ve işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı bir şekilde gerekçesini göstererek iki sınır arasında temel cezayı belirleme yetki ve görevi yüklemiştir. Hâkimin temel cezayı belirlerken dayandığı gerekçenin TCK'nın 61/1. maddesine uygun olarak, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki ile ilgili dosyaya yansıyan bilgi ve belgelerin isabetle değerlendirildiğini gösterir biçimde yasal ve yeterli olmalıdır.

Öte yandan, **sanığın** sabıka kaydında **geçmiş hükümlülüklerinin bulunması, koşullarının varlığı halinde tekrerrür uygulamasında dikkate alınabilecek bir husus olup** TCK'nın 61. maddesinde sayılan **temel cezanın belirlenmesi ölçütleri arasında bulunmadığından alt sınırdan uzaklaşma gerekçesi olarak kullanılamayacaktır.**

aykırı olan fiilin ifade ettiği haksızlık bakımından derecelendirmeye tabi tutulabilir. Buna karşılık, hukuka aykırılığın derecelendirilmesinden veya yoğunluktan söz edilemez.

Bu ölçütlerden birincisi, “*suçun işleniş biçimi*”dir. Cinsel saldırı suçunun mağdurun eşinin veya çocuklarının huzurunda işlenmesi (m. 102), bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

İkinci ölçütü, “*suçun işlenmesinde kullanılan araçlar*” oluşturmaktadır. Örneğin devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla oluşturulmuş silahlı örgütün (m. 314) bünyesindeki silahların türü, niteliği ve sayısı bu bağlamda temel cezanın tayininde göz önünde bulundurulur.

Üçüncü ölçüt, “*suçun işlendiği zaman ve yer*”dir. Hırsızlık suçunun (m. 141) bayram, düğün veya cenaze gününün sağladığı kolaylıktan yararlanılarak, keza hakaret suçunun (m. 125) ibadethanede işlenmesi, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Dördüncü ölçüt olarak, “*suçun konusunun önem ve değerini*” dikkate almak gerekir. Örnek: Suçun konusunu oluşturan malın değerinin fazla veya az olması; zarar verilen malın fakir bir kişiye ait olması, kişi açısından zaruri ihtiyaç duyulan eşya olması.

“*Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı*” ise, beşinci ölçüt olarak kabul edilmiştir. Örnek: Kasten yaralama suçunda ika edilen yaranın büyüklüğü; mala zarar verme suçunda verilen zararın fazla veya az olması; somut tehlike suçlarında gerçekleşen tehlikenin ağırlığı.

Altıncı ölçütü, (f) bendindeki ifadeye göre, “*failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı*” oluşturmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, temel cezanın belirlenmesinde ölçü alınan hususlar, işlenen fiilin **haksızlık içeriği** üzerinde etkili olmaktadır. Halbuki, bu bentte, “***kusurun ağırlığı***”ndan söz edilmiştir. Dolayısıyla, bu bent kapsamında kişinin işlediği suçla ilgili olarak kusurluluğu bağlamında da bir değerlendirme yapılması gerekmektedir^{435, 436}.

Suçla konu edilen sahte paranın miktarı, gerek 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesinde, gerekse aynı Yasanın 197. maddesinde özel bir alt sınırdan uzaklaşma gerekçesi olarak sayılmadığına göre, TCK’nın 61/1-d maddesinde yer alan “*suçun konusunun önem ve değeri*” kapsamında değerlendirilmelidir.”: CGK, **29.9.2009**, E. 2009/8-124, K. 2009/224.

⁴³⁵ Ceza Genel Kurulu’nun **7.7.2009** tarihli ve E. 2009/9-62, K. 2009/191 sayılı Kararında, birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan bir trafik kazasına sebebiyet veren sürücü hakkında verilecek olan cezanın belirlenmesi bağlamında şu değerlendirmelerde bulunulmuştur:

“5237 sayılı TCK’nın birden fazla kişiyi taksirle öldürme suçunu düzenleyen 85/2. madde ve fıkrasında;

“*Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.*”

şeklindeki düzenlemeye yer verilmiştir.

Aynı Yasanın “taksiri” düzenleyen 22/4. maddesinde;

“Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.”

hükmü yer almaktadır.

5237 sayılı TCK’nın “cezanın belirlenmesini” düzenleyen 61. maddenin 1. fıkrasındaki düzenleme;

“Hakim; somut olayda; a) Suçun işleniş biçimini, b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları, c) Suçun işlendiği zaman ve yeri, d) Suçun konusunun önem ve değerini, e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını, g) Failin güttüğü amaç ve saiki, göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler”, aynı maddenin 10. fıkrasındaki düzenleme ise, “Kanunda açıkça yazılı olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de değiştirilebilir.”

şeklindedir.

O halde; ... işlenmiş olan herhangi bir suç nedeniyle alt ve üst sınır arasında bir ceza belirlenmesi gerektiğinde; göz önünde bulundurulması gereken tek kıstas 5237 sayılı TCK’nın 61. maddenin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Ancak taksirle işlenen suçlar açısından yasa koyucu aynı Yasanın 22. maddenin 4. fıkrasına bir kıstas daha eklemiştir. Bu durumda, alt ve üst sınır arasında belirlenmesi gereken cezanın taksirli bir suça ait olması durumunda bunun Yasanın 61/1 ve 22/4. madde ve fıkralarında yer alan ölçütlere göre yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, 61/1. maddedeki kıstaslar genel nitelikli olup; bunların her biri, her suça uymayabileceğinden, her suç için tüm kıstasların değil, sadece ilgili suça uyan kısımların nazara alınması gerekir. Sözgelimi, taksirli suçlar açısından 61/1. maddenin (g) bendinde yer alan “failin güttüğü amaç ve saik” kıstası uygulanamayacaktır.

Öyleyse, öncelikle 61. maddenin 1. fıkrasındaki kıstaslardan hangilerinin olayımız açısından uygulanabilir olduğu belirlenmelidir:

Somut olay açısından yapılan değerlendirmede; 61. maddenin 1. fıkrasındaki kıstaslardan, (a), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alanların uygulanabilir, diğerlerinin ise uygulanamaz olduğu görülmektedir. Zira, (a) bendinde “suçun işleniş biçimi”, (c) bendinde “suçun işlendiği zaman ve yer”, (d) bendinde “suçun konusunun önem ve değeri”, (e) bendinde “meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı”, (f) bendinde ise “failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı” yer almaktadır; bunun dışında, (b) bendindeki “suçun işlenmesinde kullanılan araçlar” ve (g) bendindeki “failin güttüğü amaç ve saik” kıstaslarının ise olayımızda uygulanma olasılığı bulunmamaktadır. Ayrıca göz önünde bulundurulması zorunlu olan bir başka ölçüt te, aynı Yasanın 22. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ve sadece taksirle işlenen suçlara özgü olan “failin kusurudur”.

Tüm bu yasal düzenlemelere göre, birden fazla kişinin öldüğü ya da yaralandığı taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde; **failin kusuru ile ölü-yaralı sayısının ve yaralanma derecesinin birlikte değerlendirilmesinin zorunlu olduğu** sonucuna varılmaktadır. Bununla birlikte, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği zaman ve yerin, **kusurun belirlenmesi sırasında suçun konusunun önem ve değeri ile meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığının da ölü-yaralı sayısı ve yaralanma derecesinin saptanması kapsamında dikkate alınacağına** ise kuşku bulunmamaktadır.

Her ne kadar, yasa koyucu **taksirli suçlar açısından** 765 sayılı TCY’nda yer alan ve **matematiksel kusur hesabına dayalı cezalandırma sisteminden vazgeçmiş** ise de, 5237 sayılı TCY’sı uygulamasında da alt ve üst sınır arasındaki cezanın meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ile suç konusunun değeri de gözetilerek fakat **ağırlıklı olarak kusura göre belirlenmesi** hakkaniyete ve yasaya uygun olacaktır. Bunun dışında, cezanın yasada yer alan objektif ölçütler terk edilerek, tamamen subjektif olan hak ve nasafet (doğrusu: “*nesafet*” – yazar-) gereğince tayin edilebileceğinin kabul edilmesi halinde ise, kişilere göre değişkenlik gösterecek olan hak ve nasafet ölçütlerinden kaynaklanan adaletsiz uygulamalar ortaya çıkacaktır.

Diğer taraftan; yargılamayı gerçekleştiren hakimın **bilirkişilerin saptadıkları kusur oranları** ile bağlı olmadığı, aksine **bilirkişilerin yapacakları teknik belirlemeler çerçevesinde failin kusurunun ne olduğunun ve bu kusurun cezanın belirlenmesinde ne derece etkin olacağının her olayın özelliklerine göre bizzat hakim tarafından** denetlenebilir ölçütlerle **belirlenmesi gerektiği**, ayrıca vurgulanması gereken önemli bir husustur.”

Ceza Genel Kurulu’nun söz konusu Kararında taksirli suçlarla ilgili olarak üzerinde durduğu önemli hususlara işaret etmek gerekir:

1) Taksirli suçlarda da failin kusurluluğunu tespit ve değerlendirme görevi, münhasıran hakim aittir.

2) Bilirkişi, taksirli suçlarda failin kusurluluğunu tespit etmeyecektir. Bilirkişinin görevi teknik belirlemelerle sınırlıdır. Bilirkişi, somut olayda, işin tekniğine ilişkin hangi kuralın ihlal edildiğini, hangi teknik eksikliklerin mevcut olduğunu, bu kural ihlali ve teknik eksiklik bağlamında kimin sorumluluğunun söz konusu olabileceğini tespit zımında bir rapor düzenlemekle yetinmelidir.

3) Taksirle işlenen suçlardan dolayı temel cezanın belirlenmesinde failin kusurluluğu, yegane (tek) ölçüt değildir. Failin kusurluluğunun yanı sıra, TCK’nın 61. maddesinin birinci fıkrasında tadadi olarak belirlenen ölçütlerden önemli bir kısmının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ancak bu değerlendirmede, sorumlu bazı ifadeler de yer verilmiştir. Kararda, “**kusurun belirlenmesi sırasında suçun konusunun önem ve değeri ile meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığının da ölü-yaralı sayısı ve yaralanma derecesinin saptanması kapsamında dikkate alınacağı**”nın söz edilmektedir. “*Suçun işleniş biçimi*”, “*suçun işlendiği yer ve zaman*” gibi; “*suçun konusunun önem ve değeri*”, “*meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı*”, “*ölü-yaralı sayısı*” ve “*yaralanmanın derecesi*”, **kusurluluğun yanında dikkate alınabilecek olan ölçütlerdir**. Oysa söz konusu Kararda, bu ölçütlerin “*kusurluluğun belirlenmesinde*” dikkate alınması gerektiği yönünde ifadeye yer verilmiştir. Bu yönü itibarıyla söz konusu kararın hukuki gerekçesi sorunludur.

⁴³⁶ “*sanığın sabıka kaydında geçmiş hükümlülüklerinin bulunması, koşullarının varlığı halinde tekerrür uygulamasında dikkate alınabilecek bir husus olup, TCK’nın 61. maddesinde sayılan temel cezanın belirlenmesi ölçütleri arasında bulunmadığından alt sınırdan uzaklaşma gerekçesi olarak kullanılamayacaktır. Bununla birlikte sabıka kaydındaki geçmiş hükümlülükler ile bu hükümlülüklerin niteliği ve sayısının, aynı Kanunun 61/1-f maddesinde yer alan “failin kastının ağırlığı”nın belirlenmesi sırasında hakim tarafından gözönüne alınabilmesinde de yasal bir engel bulunmamaktadır.*”: CGK, **25.12.2012**, E. 2012/15-1280, K. 2012/1864; CGK, **9.4.2013**, E. 2012/15-1534, K. 2013/132.

Kararın iktibas ettiğimiz kısmının birinci cümlesindeki tespit doğrudur. Ancak ikinci cümlede varılan kanaat doğru değildir. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, 61. maddenin birinci fıkrasında “kastın ağırlığı” değil, “kasta dayalı kusurun ağırlığı” ibaresi kullanılmıştır. Yeni TCK’nın sistemi itibarıyla suçun manevi unsurlarına ve kusurluluğa ilişkin olarak yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, her iki ibarenin ifade ettiği anlamların birbirinden farklı olduğu görülecektir.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, kişinin başka suçlardan sabıkasının olmasının bilahare işlediği suça ilişkin kastı bakımından herhangi bir etkisinden söz edilemez. Genel Kurul kararında yer verilen ve “kastın ağırlığı”na etkisinin olduğu kabul edilen geçmiş “hükümlülüklerin niteliği”nden neyin ifade edilmek istendiği anlaşılamamıştır.

Bu karar, mülga 765 s. TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde oluşmuş ve bilimsel temeli olmayan belirli kabullerin günümüzdeki yansımalarına bir örnek teşkil etmektedir.

Ceza Genel Kurulu’nun bilahare verdiği bir kararda bu değerlendirmeden sarfınazar edilmiştir:

“... *sanığın adli sicil kaydında geçmiş hükümlülüklerinin bulunması, şartlarının varlığı halinde tekerrür uygulamasında dikkate alınabilecek bir husus olup, TCK’nın 61. maddesinde sayı-*

Kanunun 21'inci maddesi bağlamında açıklandığı üzere, yeni TCK'nın hazırlanmasında esas alınan suç teorisinde kast ve taksir, birer kusurluluk şekli olarak değil, haksızlığın birer gerçekleştiriliş şekli olarak dikkate alınmıştır.

Kasten işlenen suçlarda, kişi işlediği suçun esasında bir haksızlık oluşturduğu hususunda hataya düşmüş olabilir. Bunun, kişi açısından “kaçınılmaz” bir hata olması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz (m. 30, f. 4). Buna karşılık, hatanın kişi açısından kaçınılabılır olması halinde, cezaya hükmolunacaktır. Bu hata, söz konusu birinci fıkranın (f) bendi hükmü bağlamında değerlendirilerek, temel ceza belirlenecektir.

Aynı şekilde, kusurluluğu ortadan kaldıran bir nedenin maddi şartlarında⁴³⁷ hataya düşülmesi halinde, bu hata kişi açısından kaçınılmaz bir hata ise, hakkında cezaya hükmolunmaz (m. 30, f. 3). Buna karşılık, bu hatanın kişi açısından kaçınılabılır olması halinde ise, hakkında cezaya hükmolunacaktır. Bu hata da, cezanın belirlenmesi sürecinde 61'inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü bağlamında değerlendirilmelidir.

Taksirle işlenen suçlarda, ilgili suç tanımındaki cezanın alt ve üst sınır arasında temel ceza belirlenirken de, kişinin taksire dayalı kusuru 61'inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü bağlamında göz önünde bulundurulacaktır.

Yeni TCK'da, olası kast ve bilinçli taksir hallerine ilişkin olarak cezanın ne suretle belirleneceğine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Şöyle ki; suçun olası kastla işlenmesi halinde, 61'inci maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen temel cezada belli bir oranda indirim yapılması gerekmektedir (m. 21, f. 2)⁴³⁸. Keza,

lan temel cezanın belirlenmesi kıstasları arasında bulunmadığından, alt sınırdan uzaklaşma gerekçesi olarak kullanılamayacaktır”: CGK, 1.10.2013, 2012/8-1343-2013/404.

⁴³⁷ Yeni TCK sisteminde bu bağlamda mütalaa edilebilecek kusurluluğu (algılama veya irade yeteneğini) ortadan kaldıran sebepler şunlardır:

- 1- Cebir veya tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin ortadan kalkması (m. 28),
- 2- Zorunluluk hali dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin ortadan kalkması (m. 25, f. 2),
- 3- Hukuka aykırı ve fakat, bağlayıcı emrin yerine getirilmesi (m. 24, f. 2 - 4),

⁴³⁸ Yargıtay **Ceza Genel Kurulu**'nun 28.5.2013 tarihli ve E. 2013/3-259, K. 2013/273 sayılı kararına konu teşkil eden, F'nin M'yi olası kastla ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı olayda, ilk derece mahkemesi, F hakkında sırasıyla, TCK, m. 86, f. 1; m. 21, f. 2; m. 87, f. 1 (bent d); m. 62 hükümlerini uygulayarak sonuç cezayı **2 yıl 6 ay** hapis cezası olarak belirlemiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu mahkumiyet hükmünün onanmasına karar vermiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu onama kararına itirazı üzerine konuyu ele alan Yargıtay Ceza Genel Kurulu Özel Dairenin onama kararını kaldırarak, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet hükmünü bozmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise, söz konusu suçun doğrudan kastla işlenmesi halinde de, TCK, m. 86, f. 1; m. 87, f. 1 (bent d); m. 62 hükümlerini uygulanarak ve m. 86, f. 1'e göre ceza alt sınırdan tayin edildiği takdirde verilebilecek sonuç ceza yine **2 yıl 6 ay** olabilecektir. Ceza Genel Kurulu'na göre, “her iki durumda da sonuç cezanın aynı olması ceza adaletine ve kanun koyucunun eylemin olası kastla işlenmesi halinde daha az cezaya hükmolunması gerektiği yönündeki amacına uygun düşmeyecektir.”

suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde ise, ilgili kanuni tanımında bilinçsiz taksir haline özgü olarak öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında belirlenen temel cezada belli bir oranda artırım yapılması gerekmektedir (m. 22, f. 3). Bu hususa ilişkin olarak, 61'inci maddenin ikinci fıkrasında hüküm bulunmaktadır:

Oysa, Ceza Genel Kurulu'na göre, olası kast nedeniyle TCK, m. 21, f. 2 hükmüne göre yapılması gereken indirimin, kasten yaralama suçunun temel şeklinden TCK, m. 86, f. 1 hükmüne göre belirlenen temel ceza üzerinden değil de, neticesi sebebiyle ağırlaşmış haline ilişkin m. 87, f. 1 hükümleri uygulanarak belirlenen cezadan yapılmış olması halinde, fail **1 yıl 3 ay** hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Ceza Genel Kurulu'na göre, “*ancak bu şekildeki kabulde ceza adaleti ve kanun koyucunun amacı gözetilmiş olacaktır ki, bu nedenle 5237 sayılı TCK'nın 21/2. maddesi uyarınca olası kast nedeniyle yapılacak indirimin 86/1 ve 87/1-d-son maddeleri uyarınca belirlenen ceza üzerinden yapılması gerektiğinin kabulünde ceza adaleti yönünden zorunluluk bulunmaktadır.*”

Ceza Genel Kurulu'nun bu kararını doğru bulmamaktayız. Karara konu teşkil eden olayda kasten yaralama suçunun temel şeklinden dolayı temel cezanın alt sınırdan belirlenmesi durumunda sonuç ceza suç doğrudan kastla işlenmesi halindeki sonuç ceza ile aynı olmaktadır. Oysa temel cezanın üst sınırdan belirlenmesi halinde sonuç cezalar arasında fark ortaya çıkacaktır. Aşağıdaki tablolar, bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır:

a) Olası kastla işlenen söz konusu suç dolayısıyla **TCK, m. 61'de belirlenen usul ve sıraya göre** cezanın hesaplanması;

	Cezanın alt sınırdan belirlenmesi halinde verilecek hapis cezası	Cezanın üst sınırdan belirlenmesi halinde verilecek hapis cezası
TCK, m. 86, f. 1	1 yıl	3 yıl
TCK, m. 21, f. 2	6 ay (azami oranda indirim yapıldığı takdirde)	1 yıl 6 ay (azami oranda indirim yapıldığı takdirde)
TCK, m. 87, f. 1 (bent d ve son cümle)	3 yıl	3 yıl
TCK, m. 62	2 yıl 6 ay	2 yıl 6 ay

b) Olası kastla işlenen söz konusu suç dolayısıyla **CGK Kararında belirlenen usul ve sıraya göre** cezanın hesaplanması;

	Cezanın alt sınırdan belirlenmesi halinde verilecek hapis cezası	Cezanın üst sınırdan belirlenmesi halinde verilecek hapis cezası
TCK, m. 86, f. 1	1 yıl	3 yıl
TCK, m. 87, f. 1 (bent d ve son cümle)	3 yıl	6 yıl
TCK, m. 21, f. 2	1 yıl 6 ay (azami oranda indirim yapıldığı takdirde)	3 yıl (azami oranda indirim yapıldığı takdirde)
TCK, m. 62	1 yıl 3 ay	2 yıl 6 ay

Bu durum karşısında, temel cezanın alt sınırdan belirlenmesi alışkanlığımızdan kaynaklanan çelişkiler nedeniyle, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine ilişkin olarak Kanunda belirlenen usul ve sıranın bozulmasının hukuki izahı bulunmamaktadır.

“Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim veya artırım, birinci fıkra hükmüne göre belirlenen ceza üzerinden yapılır.”

Başka bir deyişle, olası kast ve bilinçli taksir, ilk defa ikinci fıkra bağlamında dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, *mükerrer değerlendirme yasağının gereği* olarak, söz konusu hallerin, birinci fıkranın (f) bendindeki *“failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı”* bağlamında temel cezanın belirlenmesinde artık dikkate alınmasına imkan bulunmamaktadır.

Haksızlık içeriği bakımından, suçun olası kastla işlenmesi doğrudan kasta nazaran daha az, bilinçli taksirle işlenmesi bilinçsiz taksire nazaran daha fazla ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Kanunun kast ve taksire ilişkin 21 ve 22'nci maddeleri hükümleri karşısında, olası kast ve bilinçli taksir ancak 61'inci maddenin ikinci fıkrası bağlamında dikkate alınabilir⁴³⁹.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; yeni TCK'da benimsenen ifade, *“kastın veya taksirin yoğunluğu”* (765 s. TCK, m. 29, f. 8) değildir. Aslında kast veya taksirin

⁴³⁹ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, 4.5.2010 tarihli ve E. 2010/1-30, K. 2010/99 sayılı kararı-na konu teşkil eden olayda; arkadaşının kına gecesinin yapıldığı eve gelen B, evin demir korkuluklarla çevrili girişindeki beton zemin üzerinde sırtı bahçeye dönük olarak sandalyede oturduğu sırada başına isabet eden tek bir kurşun ile vurulur ve ölür.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kurduğu mahkumiyet hükmünde, O'nun B'yi olası kastla öldürdüğünü kabul eder. Yargıtay 1. CD ve Ceza Genel Kurulu, bu kabulün dosya içeriği ile uyumlu olduğu yargısına varır.

Olası kastla işlenen öldürme suçundan dolayı hükmolunacak cezanın ne şekilde hesaplanması gerektiği, sorun olarak ortaya çıkmıştır.

TCK'nın 61. maddesi hükümlerine göre, olası kastla işlenen öldürme suçundan dolayı verilecek cezanın hesaplanmasında aşağıdaki usul ve sıra takip edilecektir:

1) Kasten öldürme suçundan dolayı **temel ceza**, TCK'nın 61. maddesinin birinci fıkrasındaki ölçütler dikkate alınarak belirlenecektir.

2) Öldürme suçunun olası kastla işlenmiş olması dolayısıyla TCK'nın 21. maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ölçü ve oranlardaki indirim, bu temel ceza üzerinden yapılacaktır (m. 61, f. 2).

TCK'nın 81. maddesinde, kasten öldürme suçunun temel şekline ilişkin olarak **müebbet hapis cezası** öngörülmüştür.

Suçun olası kastla işlenmiş olması dolayısıyla, TCK'nın 21. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, sanık hakkında **yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına** hükmolunması gerekmektedir.

TCK'nın 81. maddesinde kasten öldürme suçunun temel şekline ilişkin olarak maktu bir ceza belirlenmiştir. Bu nedenle, suçun temel şekline ilişkin olarak temel cezanın belirlenmesi bakımından 61. maddenin birinci fıkrasındaki ölçütlerin göz önünde bulundurulmasına gerek yoktur.

Buna karşılık, suçun olası kastla işlenmiş olması dolayısıyla, temel cezadan yapılacak olan indirimin alt ve üst sınırlar arasında belirlenmesinde, 61. maddenin birinci fıkrasındaki ölçütlerin yanı sıra, 3. maddenin birinci fıkrası hükmünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu itibarla, sanık hakkında öldürme suçunu olası kastla işlemiş olması dolayısıyla 21. maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre verilecek cezanın, 61. maddenin birinci fıkrasındaki ölçütler dikkate alınarak belirlenmesi gerekir.

yoğunluğundan söz edilemez. Bu ifade, kast ve taksirin birer kusurluluk şekli olduğu yönündeki klasik anlayışın bir yansımasıdır.

Temel cezanın belirlenmesinde başvurulabilecek son ölçütü, “*failin güttüğü amaç ve saik*” oluşturmaktadır. Örneğin, “*kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında*” mala zarar verme suçunun işlenmesi sırasında Devletin insan veya toprak unsurunun kapsamına yönelik bir saik ve mülahaza ile hareket edilmesi, 152'nci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir ölçüt olarak mütalaa edilmelidir. Ancak, *mükerrer değerlendirme yasağının gereği* olarak, bu amaç veya saikin, ilgili suçun temel veya nitelikli şekline ilişkin bir unsur oluşturmaması gerekir.

Mükerrer değerlendirme yasağının gereği olarak, birinci fıkra da belirtilen hususların suçun temel veya nitelikli şekline ilişkin unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz (m. 61, f. 3)⁴⁴⁰.

⁴⁴⁰ Trabzon Bolu, ve Bafra Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından, 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 12. maddesine 15.4.2020 tarihli ve 7243 sayılı Kanunla (m. 28) eklenen ikinci fıkrası hükümlerinin Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu fıkra hükmü şu şekildedir:

“Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yap-tırmamak için direnme (madde 265) suçlarında;

a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır.

b) Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hü-kümleri uygulanmaz.”

İptal talepleri esas itibarıyla, söz konusu kanun değişikliği ile kasten yaralama ve hakaret suçlarından dolayı cezaya hükmederken mükerrer değerlendirme yasağının ihlâl edilmiş ol-masına dayandırılmıştır. TCK'deki düzenlemeleri itibarıyla söz konusu suçların görevinin ge-reklerine uygun hareket etmesi dolayısıyla kamu görevlisine karşı işlenmesi, bu suçlar baki-mından bir nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir.

TCK, m. 86, f. 3, bent c hükmüne göre, kasten yaralama suçunun görevinin gereklerini yerine getiren kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde, temel ceza yarı oranında artırılır.

Keza, TCK, m. 125, f. 3, bent a hükmüne göre, hakaret suçunun görevinin gereklerini yerine getiren kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde, verilecek temel cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hal böyle iken, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 12. maddesine 15.4.2020 tarihli ve 7243 sayılı Kanunla (m. 28) eklenen ikinci fıkra hükmü gereğince, söz konusu suç-ların, çalıştığı kurum göz önünde bulundurulmaksızın kamu görevlisi sıfatı izafe edilen sağlık mesleği mensubu kişilere karşı görevlerinin gereklerine uygun hareket etmeleri dolayısıyla iş-lenmesi halinde, “*ilgili maddelere göre tayin edilecek cezalar (tekrar) yarı oranında artı-rı*”acaktır. Bu suretle “*mükerrer cezalandırmanın hukuk devleti ve ölçülülük ilkelerini ihlal ettiği, ayrıca mağdur olan sağlık çalışanlarına böyle bir ayrıcalığın tanınmasının kanun önünde eşitlik ilkesiyle çeliştiği,*” ileri sürülmüştür (pn. 25). Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki gerekçelerle bu iptal talebini reddetmiştir (13.10.2021, E. 2020/91, K. 2021/73):

“Kanun koyucu itiraz konusu kurallarla sağlık personeline yönelen kasten yaralama ve hakaret fiillerinin diğer kamu görevlilerine oranla daha fazla cezalandırılmasını ve anılan suçlar ile tehdit suçunda ise hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümlerin uygulanmamasını öngörmektedir. Bu çerçevede kurallarla sağlık personeline karşı yukarıda belirtilen suçların işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığı, bir başka ifadeyle bu suçlar yönünden caydırıcılığın sağlanmak istendiği anlaşılmaktadır.” (pn. 30)

“... İtiraz konusu kural sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama ve hakaret suçlarında 5237 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenecek olan **sonuç ceza üzerinden** yarı oranında bir **artırım** öngörmektedir. Kural özel ya da kamu sağlık çalışanları arasında bir ayırım yapmadan tamamını kapsamaktadır. Kuralların yer aldığı maddenin üçüncü fıkrasında ise özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle sağlık çalışanlarına karşı görevlerinden dolayı işlenen kasten yaralama ve hakaret suçlarında cezanın belirlenmesinde **iki nitelikli hâlin** değerlendirilmesi söz konusu olacaktır. Bununla birlikte hem suçların temel şekli hem de nitelikli hâlleri için 5237 sayılı Kanun'da belirli aralıklarda cezanın türü ve miktarı düzenlenmiştir. Suçlar için öngörülen yaptırımın niteliği ve ağırlığı ile kanun koyucunun Anayasa'ya bağlı kalmak şartıyla ceza siyasetinin bir parçası olarak takdir yetkisi kapsamında öngörülüp kuralla ulaşmak istediği amaç birlikte gözetildiğinde kuraldaki ceza artırımının orantılı olmadığı söylenemez.” (pn. 32)

“... Sağlık hizmetleri niteliği itibarıyla belirli bir düzen içinde sunulması gereken, kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez, ertelenemez ve ikame edilemez hizmetlerdendir. Kanun koyucunun sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek itiraz konusu kuralı öngördüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kuralların sağlık personeline karşı anılan nitelikteki suçların işlenmesini önleme amacıyla düzenlendiği açık olup bu amaçla öngörülen farklı muamelenin makul ve nesnel bir temele dayanmadığı söylenemez.” (pn. 41)

Türk Ceza Kanunu'nda kamu görevlisi kavramı dışında “yargı görevi yapan” ibaresi kullanılmıştır. TCK, m. 265'deki suç tanımında, görevini yapmasını engellemek amacıyla yargı görevi yapan kişiye cebir veya tehdit kullanılması, bu suçun temel şekline nazaran, yani herhangi bir kamu görevlisine karşı işlenmesine nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Kanunun düzenlemelerinde hassasiyet gösterilen temel kurallardan biri, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi (şahsileştirilmesi) bağlamında mükerrer değerlendirme yasağıdır. Bu yasağın somut olay bağlamında cezanın ölçülülüğü bakımından büyük bir önem taşımaktadır. İlgili suç tanımlarında ceza miktarı ölçülü olarak belirlenmemiş olabilir. Bu değerlendirmeler her bir suç tanımı bakımından yapılabilir. Ancak, aynı sebebin, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi bağlamında mükerrer dikkate alınmasının ölçülülük ilkesini ihlâl edeceği hususunda kuşku bulunmamaktadır. Ölçülülüğün Anayasal ilkelerle ilgisinin bulunduğu, izahtan varestedir.

Görevinin gereklerini yerine getirmesi dolayısıyla, sağlık çalışanına karşı cebir, tehdit veya hakaret fiillerinin işlenmesi dolayısıyla, diğer kamu görevlilerine nazaran daha ağır bir ceza ile cezalandırma yoluna gidilebileceği, yasama organının takdirinde olan bir husustur. Ancak, bu takdir kullanılırken yapılan kanuni düzenleme ile hukuk kurallarının altüst edilmemesi gerekir. İlgili kanunî düzenlemede yer almamakla birlikte, Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde ilgili suçun “**sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline**” karşı işlenmesi halinde, artırmanın **sonuç ceza** üzerinden yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bunun, somut olayda uygulanacak ceza yaptırımı bakımından ölçülülüğünden söz edilemez.

Şöyle bir örnekle konuya açıklık getirmek isterim.

Çalıştığı sağlık kuruluşunun kamu veya özel olması arasında ayırım yapılmaksızın, “**sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline**” karşı görevi sebebiyle kasten yaralama suçunun işlenmesi dolayısıyla temel TCK, m. 86, f. 1 hükmüne istinaden üst sınırdan **3 yıl** olarak belirlenmiş olsun.

61'inci maddenin birinci fıkrasında sayılan temel cezanın belirlenmesine ilişkin bu ölçütler **sınırlı sayıdadır**. Bu bakımdan, yeni TCK ile 765 s. Kanunun arasında bir farklılık bulunmaktadır. 765 s. TCK'nın 29'uncu maddesinin son fıkrasında “*gibi hususlar*” ifadesi kullanılarak, temel cezanın belirlenmesinde başvurulacak ölçütlerin sınırlı olmadığı kabul edilmişti.

Keza, 765 s. TCK'nın 29'uncu maddesinin son fıkrasının düzenlemesine göre, “*failin ... geçmişi, şahsi ve sosyal durumu, fiilden sonraki davranışı*” da, temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınmaktaydı. Dikkat edilmelidir ki, bunlar, işlenen fiilin haksızlık içeriği bakımından dikkate alınabilecek hususlar değildir. Bu hususlar ancak cezanın bireyselleştirilmesi bağlamında göz önünde bulundurulabilir. Nitekim, yeni TCK'nın “*Takdiri indirim nedenleri*” başlıklı 62'nci maddesinde, “*failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları veya cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri*” ifadesine yer verilmiştir (f. 2).

765 s. TCK'nın bu düzenlemesi, esasında *mükerrer değerlendirme yasağının* ihlâli mahiyeti taşımaktaydı. Çünkü aynı nedenler, ayrıca takdiri indirim nedenleri olarak bu Kanunun 59'uncu maddesi hükmü çerçevesinde dikkate alınmaktaydı.

Suçun sağlık personeline karşı işlenmiş olması dolayısıyla, 3359 s. K, ek m. 12, f. 3, yollamasıyla TCK, m. 86, f. 3 hükümlerine istinaden, yarı oranında artırılarak ceza, **4 yıl altı aya** çıkacaktır. Kişi hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulandığı durumda bu cezadan 9 ay indirim yapılacak ve sonuç ceza, **3 yıl 9 ay** olacaktır. 3359 s. K, ek m. 12, f. 2 hükmüne istinaden bu ceza tekrar yarı oranında artırılacaktır. Bu durumda nihai ceza, **4 yıl 19 ay 15 gün** olacaktır.

Aynı suç, “*sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline*” değil de, herhangi bir kamu görevlisine, örneğin **görevi sebebiyle, bir öğretmene, hâkime veya Cumhuriyet savcısına karşı işlendiğinde** verilebilecek olan en yüksek ceza, **3 yıl 9 ay hapis cezası** olacaktır.

Keza aynı fiil, masum herhangi bir kişiye karşı işlendiğinde verilebilecek olan sonuç ceza, **2 yıl 6 ay** olabilecektir.

Aynı kasten yaralama fiili, **görevini yapmasını engellemek amacıyla**, bir hâkime veya Cumhuriyet savcısına karşı işlendiğinde, TCK, m. 265, f. 2 hükmüne göre, temel ceza üst sınırdan **4 yıl** olarak belirlenebilecektir. Kişi hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulandığı durumda **sonuç ceza, 3 yıl** olacaktır.

Bu farklı sonuçların ölçülülük ilkesini ihlâl ettiği konusunda kuşku bulunmamaktadır. Ölçülülüğün de adaletin bir gereği olduğu izahtan varestedir.

Anayasa Mahkemesi kararında bu şekilde bir örneklemeye gidilemeyeceğinin idrakindeyim. Ancak, yapılan düzenlemenin ölçülülük ilkesiyle çeliştiğini ve bu nedenle anayasaya aykırı olduğunu görmezlikten gelemeyiz.

Anayasa Mahkemesinin kararında, yasama organına bu bağlamda yapacağı düzenlemede yol göstericilik özelliği taşıyan açıklamalara yer verilebilirdi. Bu sebeple, belirlenen ilkeler doğrultusunda kanuni düzenleme yapılabilmesini sağlamak amacıyla iptal kararının yürürlüğe girmesinin ileri bir tarihte ertelenmesine karar verilebilirdi.

II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

A. Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Adli para cezası, yeni TCK'da hapis cezasına seçenek veya hapis cezasının yanında bir yaptırım olarak kabul edilmiştir.

Adli para cezasının hapis cezasının yanında seçenek yaptırım olarak kabul edildiği hallerde, *üç aşamalı* bir yöntem izlenecektir. Mahkeme, *birinci aşamada* kişi hakkında hapis cezasına mı yoksa adli para cezasına mı hükmedeceğini karara bağlamalıdır. Bu tercihin yapılmasında sadece *suçlunun kişiliği* dikkate alınmalıdır. Bu tercih, aslında cezanın bireyselleştirilmesi yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu belirlemede, 62'nci maddenin ikinci fıkrasındaki *“failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar”*ın yanı sıra, ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur^{441, 442}.

Bu tercih sonucunda mahkemenin kişi hakkında hapis cezasına hükmetmeyi kararlaştırması halinde, hapis cezasına ilişkin belirleme ve bireyselleştirmeye ilişkin usul ve sıra izlenerek sonuç ceza belirlenecektir⁴⁴³.

Bu tercih sonucunda mahkemenin kişi hakkında adli para cezasına hükmetmeyi kararlaştırması halinde, *ikinci aşama* başlamaktadır. Bu aşamada da yine 61'inci madde hükmü esas alınacaktır. Bu itibarla, adli para cezasının hesaplanmasında esas alınacak gün sayısı, 61'inci madde hükmüne göre belirlenecektir. Bu belirlemede, hapis cezasının belirlenmesi ve bireyselleştirilmesindeki usul ve sıra izlenecektir. Bu husus, adli para cezasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 52'nci maddenin gerekçesinde açık bir şekilde vurgulanmıştır:

“Adli para cezasına hükmederken hâkim önce, suç karşılığı olarak kanundaki sınırlar arasında gün birimi sayısını saptayacaktır. Toplam gün birimi sayısı belirlenirken hâkim cezanın bireyselleştirilmesindeki ölçülerini esas alarak bir sonuca varacaktır.”

⁴⁴¹ Bu mülahazalarla, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun aşağıdaki kararında yer verilen açıklamaları doğru bulmuyoruz:

“TCK'nda hapis ve adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü durumlarda temel cezanın nasıl belirlenmesi gerektiğine ilişkin mükerrer sanıklar dışında ayrıca bir düzenleme yer almadığından, bu ahvalde temel ceza, TCK'nın 61. maddesinde gösterilen kıstaslara göre belirlenmelidir.

Sanık hakkında hapis ve adli para cezasının seçenek yaptırım olarak öngörüldüğü TCK'nın 203. maddesinde düzenlenen mühür bozma suçunda yerel mahkemece temel cezanın 61. maddeye uygun şekilde; “suç konusunun önem ve değeri, suç kastının yoğunluğu, zararın ve tehlikenin ağırlığı nazara alınarak taktiren” denilmek suretiyle **hapis cezası olarak belirlenmesi**, ... kanuna uygun ve yeterlidir.” CGK, **8.10.2013**, E. 2012/5-1393, K. 2013/412.

⁴⁴² Bu açıklamalarımıza eleştiri için bkz. İŞOĞLU, Adli Para Cezası, sh. 213.

⁴⁴³ ÜZÜLMEZ, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 215.

Adli para cezasının hesaplanmasında esas alınan **temel gün** bu suretle belirlenecektir. 61. maddenin ikinci ve devamı fıkralarındaki artırma ve indirmelerin bu temel gün üzerinden yapılması gerekmektedir.

Ancak, yeni TCK'nın bu düzenlemeleri, belirlenen temel gün sayısı ile failin bir gün karşılığı ödeyebileceği para miktarının çarpımı sonucunda parasal değer olarak temel cezanın belirlenmesi ve 61. maddenin ikinci ve devamı fıkralarındaki artırma ve indirmelerin bu parasal değer üzerinden yapılması gerektiği yönünde yanlış bir yorumlamaya tabi tutulmuştur⁴⁴⁴. Bu yoruma dayalı yanlış uygulamanın önüne geçmek amacıyla, TCK'nın 61. maddesine, 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla, sekizinci fıkra olarak yeni bir hüküm eklenmiştir. Buna göre;

“Adli para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler, gün üzerinden yapılır. Adli para cezası, belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur.”

Bu hükmün **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Adli para cezasının hesaplanmasında başta Yargıtay olmak üzere hâkim ve savcılarda oluşan tereddüdün giderilmesi amacıyla, söz konusu maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir.”⁴⁴⁵

Keza, adli para cezasının hesaplanmasında esas alınan **temel gün** belirlenirken, beş gün ile yediyüzotuz gün arasında bir gün mü, yoksa ilgili suç tanımındaki hapis cezasının alt ve üst sınırlarının mı esas alınacağı konusunda da doktrin ve uygulamamızda tereddüt hasıl olmuştur⁴⁴⁶. Bu tereddütleri gidermek amacıyla, TCK'nın 61. maddesine, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere, 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla, yeni bir fıkra eklenmiştir. Buna göre;

“Adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz.”

Maddeye eklenen bu dokuzuncu fıkra hükmünün **gerekçesi** şu şekildedir:

“Adli para cezasının hapis cezasına seçimlik yaptırım olarak kabul edildiği hallerde, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi bağlamında mahkeme, önce kişi hakkında hapis cezasına mı yoksa adli para cezasına mı hükmedeceğini karara bağlar. Bu tercihin yapılmasında sadece suçlunun kişiliği dikkate alınmalıdır. Bu tercih, aslında cezanın bireyselleştirilmesi yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu

⁴⁴⁴ Bkz. ÇINAR, Türk Ceza Hukukunda Cezalar, sh. 87, 92.

⁴⁴⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 3.

⁴⁴⁶ Bkz. ÜZÜLMEZ, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 216.

belirlemede failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususların yanı sıra, ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.

Bu tercih sonucunda mahkemenin kişi hakkında adli para cezasına hükmetmeyi kararlaştırması halinde, adli para cezasının hesaplanmasında esas alacağı gün sayısını, hapis cezasının belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi ile ilgili olarak 61'inci maddede öngörülen usul ve sırayı izleyerek belirleyecektir.

Bu hesaplamada temel gün belirlenirken, beş gün ile yediyüzotuz gün arasında bir gün mü, yoksa ilgili suç tanımındaki hapis cezasının alt ve üst sınırının mı esas alınacağı konusunda, uygulamada bir tereddüt oluşmuştur. Bu tereddüdün giderilmesi için, işbu fıkra hükmü madde metnine eklenmiştir.

Bu hükme göre, adli para cezasının hesaplanmasına ilişkin temel gün belirlenirken, ilgili suç tanımındaki hapis cezasının alt ve üst sınırının göz önünde bulundurulması gerekir. Aksi takdirde, adli para cezasının ödenmemesi halinde uygulanacak hapis süresi bakımından dengesiz sonuçlar ortaya çıkabilir.

*Bu suretle belirlenen temel gün üzerinden 61'inci maddedeki usul ve sıraya göre artırma veya indirim yapmak suretiyle **sonuç gün** sayısı belirlenir.*⁴⁴⁷

Üçüncü aşamada ise kişinin, ekonomik ve diğer şahsi hâlleri göz önünde tutularak bir gün karşılığı ödeyebileceği para miktarı belirlenir. Mahkeme, bu miktarı kişinin malvarlığını, bir günde kazandığı veya kazanması gereken geliri, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sayısını dikkate alarak takdir edecektir. Ancak Kanunda, bu miktarın alt sınırı yirmi, üst sınırı ise yüz Türk Lirası olarak belirlenmiştir (m. 52, f. 2)⁴⁴⁸. Dikkat edilmelidir ki, kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği para miktarının belirlenmesinde, işlediği suç göz önünde bulundurulmaz. Bu bakımdan, adli para cezasının bireyselleştirilmesi yöntemlerinden biri de, kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği para miktarının belirlenmesinde tezahür etmektedir. Madde **gerekçesinde** bu husus, şu şekilde vurgulanmıştır:

“Gün para cezası sisteminin temel amacı, para cezasının kişinin ödeme gücüne göre belirlenmesi yoluyla, suç işleyen zengin ile fakir arasındaki eşitsizliği gidermektir.”

Yine madde **gerekçesinde** ifade edildiği üzere; “... suç işleyen kişinin ekonomik durumu dikkate alınmadan hükmolunan para cezası, eşitlik ilkesine aykırı so-

⁴⁴⁷ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Sıra Sayısı: 1255, sh. 2.

⁴⁴⁸ Bu alt ve üst sınırlara ilişkin eleştiri için bkz. İŞOĞLU, Adli Para Cezası, sh. 211 vd.

nuçlar doğurmaktadır; (ö)deme gücü olan kişi üzerinde etkisi olma(makta), ödeme gücü olmayanı ise sonuçta yine infaz kurumuna gönderilmesini sonuçla”maktadır.

Sonuçta mahkeme tarafından belirlenen kişinin bir gün için ödeyebileceği para miktarı ile sonuç gün sayısı çarpılmak suretiyle, adli para cezasının miktarı tespit edilmektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu sistemde belirlenen para cezasının miktarı üzerinden bir artırım veya indirim yapılmamaktadır. Bütün artırım ve indirimler, adli para cezası miktarının hesaplanmasında esas alınan sonuç günün belirlenme sürecinde temel ceza üzerinden yapılmaktadır.

Madde metninde adli para cezasının bireyselleştirilmesine ilişkin bir başka hükme daha yer verilmiştir. Buna göre, mahkeme, *“ekonomik ve şahsi hâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde ödemesine de karar verebilir.”* (m. 52, f. 4).

B. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Adli para cezasının hapis cezasının yanı sıra bir yaptırım olarak öngörüldüğü hallerde mahkeme kişi hakkında önce hapis cezasını 61'inci maddede belirlenen esas ve sıraya göre belirleyecektir.

Ekonomik çıkar amacına yönelik olarak işlenen bazı suçlarda suçun işlenmesi suretiyle bir menfaatin elde edildiği muhakkak görülmekle birlikte, ne kadar gelir elde edildiği bazı hallerde belirlenememektedir.

Elde edilen gelirin miktarının belli olması halinde, Kanunun kazanç müsaderesine (m. 55) ilişkin hükümleri çerçevesinde bu gelirin müsaderesi cihetine gidilecektir.

Ancak, elde edilen gelirin miktarının belirlenememesi halinde, müsadere kararı vermek mümkün olmayacaktır. İşte bu durum gözönünde bulundurularak, ilgili suç tanımlarında hapis cezasının yanı sıra adli para cezası öngörülmüştür.

Zira, yeni TCK'nın benimsediği temel düşünceye göre; **suç işlemek bir kazanç kaynağı olarak görülemez ve suçtan elde edilen gelir, kişinin yanında kâr olarak kalamaz.**

Suçtan elde edilen gelirin miktarının belirlenemediği hallere özgü olarak, hapis cezasının yanı sıra hükmolunacak adli para cezasının belirlenmesinde TCK'nın 61'inci maddesinin birinci fıkrasındaki ölçütlerin yanı sıra, suçu işlemek suretiyle kişinin elde ettiği takdir edilen gelir miktarı göz önünde bulundurulacaktır.

Bu suretle, ilgili suç tanımında belirlenen üst sınır ile adli para cezası için Kanunda kabul edilen genel alt sınır (beş gün) (m. 52, f. 1) arasında bir gün tayin edilecektir.

Özellikle iştirak halinde işlenen suçlarda her bir suç ortağının suçun işlenmesinden elde ettikleri menfaat miktarı takdir edilerek, adli para cezasının hesap-

lanmasında esas alınacak gün sayısı bu alt ve üst sınır arasında belirlenecektir. Örneğin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, örgütün yöneticisi konumundaki kişi hakkında verilecek adli para cezasının miktarı ile örgütün getir götür işlerini takip eden basit bir elemanı hakkında hükmolunacak adli para cezasının miktarı arasında önemli farklılık bulunmalıdır⁴⁴⁹.

Fakat, yeni TCK'da benimsenen yaptırım teorisine ilişkin bu temel felsefe farklılığına rağmen, eski alışkanlıklarımızın bir yansıması olarak, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı **Bankacılık Kanunu** gibi, 1 Haziran 2005 tarihinden sonra kabul edilip yürürlüğe giren kanunlarda da suç olarak tanımlanan çeşitli fiiller karşılığında *alt ve üst sınırı belirlenmiş hapis cezasının yanı sıra yine gün olarak alt ve üst sınırı belirlenmiş adli para cezasına* yer verilmiştir.

Bu gibi durumlarda, adli para cezasının sonuç günün belirlenmesinde izlenecek yöntem, hapis cezasının belirlenmesinde izlenen yöntemle aynı olacaktır.

III. Suçun Nitelikli Halleri

Somut olayda bir suçun nitelikli halleri gerçekleştiği takdirde, izlenecek yöntem, 61'inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenmiştir:

“Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla nitelikli hâllerin gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce artırma sonra indirme yapılır.”

Bir suçla ilişkin nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda, temel cezada önce artırma yapılacaktır. Bu nitelikli haller kapsamında önce, **suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurları** göz önünde bulundurulmalıdır.

Kanunda çeşitli suç tanımları bağlamında, suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlarına yer verilmiştir. Bazı suç tanımlarında bu nitelikli unsurların gerçekleşmesi halinde, temel cezada belli bir oranda artırım yapılması öngörülmüştür (m. 99, f. 5, ikinci cümle; m. 101, f. 1, ikinci cümle; m. 102, f. 3; m. 103, f. 3, 4; m. 109, f. 3, 5; m. 119, f. 1; m. 125, f. 4; m. 130, f. 1 -ikinci cümle-; m. 143).

Bu durumda önce, işlediği suç dolayısıyla kişi hakkında temel cezayı 61'inci maddenin bir ve ikinci fıkraları hükümlerine göre belirlemek gerekir. İşlenen

⁴⁴⁹ Örneğin uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen kazancın miktarının tespit edilmesi halinde bu kazanç müsadere edilecektir. Üzülmüş'e göre, bu durumda, “ayrıca adli para cezasına hükmedilmemesi gerektiği düşünülebilir ise de, kanun koyucu bu tür suçlarda hapis ve adli para cezasının birlikte” uygulanmasını öngördüğü için, tespit edilen kazanç müsadere edilse bile, ayrıca adli para cezasına hükmetmek gerekir (ÜZÜLMÜŞ, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 217, dn. 63).

suç açısından fail hakkında daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurun gerçekleşmesi halinde, bu temel cezada, madde metninde belirlenen oranda artırma yapmak gerekecektir (m. 61, f. 4).

Kanunda, çeşitli suç tanımlarında, **suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinde** de, temel veya nitelikli şekline göre belirlenen cezada belli bir oranda artırım yapılması öngörülmüştür (m. 87, f. 1, 2, 3; m. 89, f. 2, 3; m. 95, f. 1, 2).

Bu durumda da, 61'inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen yöntem izlenecektir.

Ancak bazı suçlarda, suçun nitelikli şekilleri tanımlanırken, verilecek ceza, suçun temel şekline ilişkin olarak belirlenen cezanın belli bir oranda artırılması şeklinde değil; suçun temel şekli imiş gibi, madde metninde alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle belirlenmiştir (m. 94, f. 2, 3; m. 96, f. 2; m. 142, f. 1, 2 - birinci cümle-; m. 149, f. 1).

Bu durumda, 61'inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen yöntemin izlenmesine gerek olmaksızın, suçun temel şekline ilişkin unsurlarla nitelikli şekline ilişkin unsurları birlikte değerlendirerek temel ceza belirlenmelidir⁴⁵⁰. Başka bir deyişle, kişi hakkında işlediği suçla ilgili olarak temel cezanın belirlenmesinde suçun hem temel şekline ilişkin hem de nitelikli şekline ilişkin unsurları birlikte göz önünde bulundurulur.

Aynı yöntemin, Kanunda bir suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerine ilişkin olarak alt ve üst sınırının gösterilmesi suretiyle cezanın belirlenmesinin öngörüldüğü hallerde de (m. 94, f. 2, 3; m. 95, f. 3; m. 98, f. 2; m. 99, f. 3, 4, 5 - birinci cümle-; m. 106, f. 2; m. 109, f. 2; m. 116, f. 4), izlenmesi gerekir.

Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerin seçimlik olarak belirlendiği suçlarda, bu nitelikli hallerin gerçekleşmesi halinde cezanın belli bir oranda artırılması gerekmektedir (m. 86, f. 3; m. 87, f. 1, 2; m. 142, f. 1, 2). Örneğin kasten yaralama suçunun daha ağır cezayı gerektiren *nitelikli unsurları*, 86. maddenin üçüncü fıkrasında belirlenmiştir. Bu unsurlardan *birinin* gerçekleştiği olaylarda, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır. Bir olayda 86. maddenin üçüncü fıkrasındaki nitelikli unsurlardan *birkaçının birlikte* gerçekleşmesi mümkündür. Örneğin, kişi anasına veya babasına karşı kasten yaralama suçunu silahla işleyebilir (bent a, e). Keza, kamu görevlisine karşı kasten yaralama suçu silahla işlenmiş olabilir (bent c, e).

Bu durumlarda da, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır. Ancak, bu olgu, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Başka bir deyişle, bu gibi durumlarda, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkrala-

⁴⁵⁰ Bkz. ÜZÜLMEZ, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 220 vd.

rına göre temel cezayı belirlerken üst sınıra yaklaşmak gerekecek ve hatta, üst sınırdan temel cezayı belirlemek mümkün olacaktır.⁴⁵¹

Keza, örneğin kişi anasına karşı işlediği kasten yaralama suçunda, mağdurun kol kemiği kırılır ve ayrıca gözü kör olur. Bu örnek olayda failin ceza sorumluluğunu belirlemek için aşağıdaki sıra ve yöntemin izlenmesi gerekir:

1. Kişi kasten yaralama suçunu işlemiştir. Bu durumda temel cezayı 86. maddenin birinci fıkrasına göre belirlemek gerekir (Belirlenen ceza, örnek olarak **2 yıl** olsun).
2. Kişi bu suçu anasına karşı işlemiştir. Bu durumda 86. maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır ($2 + 1 = \mathbf{3 \text{ yıl}}$) (m. 86, f. 3).
3. İşlenen kasten yaralama sonucunda mağdurun gözü kör olmuştur. Bu durumda, 86. madde hükümlerine göre verilen ceza, iki kat artırılacaktır ($3 + 3 + 3 = \mathbf{9 \text{ yıl}}$) (m. 87, f. 2).
4. Mağdurun aynı zamanda kolu kırılmıştır. Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden birisi kemik kırılmasıdır (m. 87, f. 3). Kasten yaralama fiili sonucunda mağdurun vücudunda kemik kırılması halinde, 86. maddeye göre belirlenen ceza, kırığın mağdurun hayat fonksiyonları üzerindeki etkisine göre, yarısına kadar artırılacaktır. Somut olayda mağdurun kol kemiği kırılmıştır. Kol kemiğinin mağdurun hayat fonksiyonları üzerindeki etkisini mahkemenin takdir etmesi gerekmektedir. Yapılan takdire göre cezanın yarı oranında artırılacağını var sayalım. Bu durumda ceza, ($3 + 1,5 = \mathbf{4,5 \text{ yıl}}$) olacaktır.

Ancak, olayda, mağdurun kol kemiğinin kırılmasının yanı sıra, gözü de kör olmuştur.

İşlenen kasten yaralama fiili sonucunda bu suçun birden fazla neticesi sebebiyle ağırlaşmış hali gerçekleşmiş olabilir. Örneğin mağdurun bir kulağındaki işitme yeteneği sürekli olarak zayıflamış ve aynı zamanda bir gözü kör olmuş olabilir. Bu durumda fail hakkında cezaya hükmederken, daha ağır cezayı gerektirmesi dolayısıyla, 87. maddenin sadece ikinci fıkrasını göz önünde bulundurmamak gerekir.

Aynı şekilde, işlenen kasten yaralama fiili sonucunda mağdurun hem kol kemiği kırılmış ve hem de gözü kör olmuş ise; fail hakkında, daha ağır cezayı gerektirmesi dolayısıyla, 87. maddenin sadece ikinci fıkrasına göre cezaya hükmetmek gerekecektir.⁴⁵² Ancak, bu gibi durumlarda, 86. maddenin birinci fıkrasına

⁴⁵¹ Bkz. ÜZÜLMEZ, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 220.

⁴⁵² Yargıtay **Ceza Genel Kurulu** da, **22.11.2011** tarihli ve E. 2011/6-191, K. 2011/235 sayılı kararında aynı yönde içtihatla bulunmuştur:

"... (K)asten yaralama sonucu mağdura TCY'nın 87/1. maddesi kapsamında bir yaralanma meydana gelmesi halinde aynı Yasanın 86. maddesine göre belirlenen cezanın bir kat artırılması gerekmektedir. Ancak Yasanın 86. maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren hallerde verilecek ceza 3 yıldan, 3. fıkrasına giren hallerde ise 5 yıldan az olamayacaktır. Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde ise, TCY'nın 86.

göre temel cezayı belirlerken üst sınıra yaklaşmak ve hatta, üst sınırdan temel cezayı belirlemek mümkündür.

Bu sıra ve yöntemle, söz konusu örnek olayda fail hakkında ($3 + 1,5 = 4,5$ yıl; $4,5 + 4,5 + 4,5 =$) **13 yıl 6 ay** hapis cezasına hükmetmek mümkün olacaktır.

Suçun temel şekline nazaran daha az cezayı gerektiren hallerinin varlığı halinde, yukarıdan beri açıklanan yöntemler izlenerek bulunan cezadan indirim yapılacaktır. Örneğin, yağma suçu silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte veya geceleyin (m. 149, f. 1) işlenmiştir; ancak, suçun konusunu oluşturan malın değeri azdır (m. 150, f. 2). Bu durumda önce, suçun 149'uncu maddenin birinci fıkrasındaki nitelikli unsurlarının gerçekleşmesi dolayısıyla ceza belirlenecektir. Suçun konusunu oluşturan malın değerinin az olması dolayısıyla 150'nci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen oranlarda indirim, bu ceza üzerinden yapılacaktır.

IV. Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Somut olayda suçun özel görünüş biçimlerinin gerçekleşmesi halinde cezanın belirlenmesi sürecinde izlenmesi gereken yöntem, 61. maddenin beşinci fıkrasında gösterilmiştir. Buna göre önce suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması hali dikkate alınacaktır. Suça teşebbüs halinde, 61. maddenin beşinci fıkrasına öngelen fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden bir indirim yapılacaktır. Bu ceza üzerinden suça teşebbüs nedeniyle Kanunun 35. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen miktar veya oranlarda indirim yapılırken, “*meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı*” göz önünde bulundurulmalıdır.

Dikkat edilmelidir ki, suçun işlenmesiyle “meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı” 61. maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince temel cezanın belirlenmesinde de dikkate alınan bir ölçütü oluşturmaktadır. Suç teşebbüs aşamasında kaldığı için, temel cezanın belirlenmesinde tamamlanmış suça özgü olarak kullanılan bu ölçüt dikkate alınmayacaktır. Zira, suç teşebbüs aşamasında kaldığı için, “*meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı*” göz önünde bulundurulurken, Kanunun 61. maddenin beşinci fıkrasına öngelen fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden 35. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktar veya oranlarda indirim yapılacaktır. Aksi takdirde, mükerrer değerlendirme yasağı ihlal edilmiş olur⁴⁵³.

maddesine göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılacaktır. Failin bir eylemi ile mağdurda TCY'nın 87. maddesinde yer verilen yaralanmaların birden fazlasının gerçekleşmiş olması halinde ise, bu maddenin ilgili fıkralarının ayrı ayrı uygulanması suretiyle en ağır sonucu doğuran artırım uygulanacaktır. Nitekim, TCY'nın 87. maddesinin tüm fıkralarında, bu maddeye göre yapılacak artırımın “yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza” olarak ifade edilen TCY'nın 86. maddesine göre belirlenen cezanın üzerine yapılacağına açıkça ifade edilmesi de bu hususu teyid etmektedir. Böyle bir halde, TCY'nın 86. maddesine göre belirlenen cezanın üzerine 87. maddedeki artırımlar ayrı ayrı uygulanarak en ağır sonucu veren fıkraya göre hüküm kurulmalıdır.”

⁴⁵³ Bkz. ÜZÜLMEZ, Erzincan ÜHFD X(2006), sh. 217, 222 vd.

61. maddenin beşinci fıkrasında benimsenen sıralamaya göre, teşebbüsten sonra, suçun birden fazla kişinin iştirakiyle işlenmesi halinde, suç ortaklarının her birinin sorumluluk statüsüne bağlı olarak haklarında hükmolunacak ceza belirlenecektir.

Ancak, belirtmek gerekir ki, Kanunun azmettirmeye ilişkin hükümleri içeren 38'inci maddesinin üçüncü fıkrasında *cezada indirim yapılmasını gerektiren bir şahsi sebebe* ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu husus, iştirak ilişkisinde suç ortaklarının sorumluluk statüsüyle alakalı değildir. Her ne kadar azmettirme bağlamında yer alan bir hüküm ise de; bu husus, yine 61. maddenin beşinci fıkrasında söz konusu edilen cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler bağlamında değerlendirilmelidir.

Cezanın belirlenmesi sürecinde, iştirakten sonra *suçların içtimama* ilişkin hükümleri dikkate alınacaktır. 61. maddenin düzenlemesinde iştirakten sonra sadece “zincirleme suç” ifadesi kullanılmıştır. Bunun nedeni, Kanunun genel hükümler kısmındaki düzenlemeleri itibarıyla cezanın belirlenmesinde sadece zincirleme suçla ilişkin hükmün (m. 43) artırma yönünde etkili olmasıdır. Kanunun düzenleme biçimi itibarıyla farklı neviden fikrî içtima halinde (m. 44), kişi, işlediği bir fiille oluşan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılacaktır. Bu cezada ayrıca bir artırım öngörülmemiştir⁴⁵⁴.

V. Kusurluluğu Azaltan Nedenler

Cezanın belirlenmesi sürecinde, Kanunun suçun özel görünüş biçimlerine ilişkin hükümlerinden sonra, *kusurluluğu azaltan nedenler* dikkate alınacaktır.

Yeni TCK'da kusurluluğu (algılama veya irade yeteneğini) etkileyen nedenler on grupta toplanmaktadır. Bu nedenler, şunlardır:

- 1- Yaş küçüklüğü (m. 31),
- 2- Akıl hastalığı (m. 32),
- 3- Sağır ve dilsizlik (m. 33),
- 4- Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma (m. 34),
- 5- Cebir veya tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi (m. 28),
- 6- Zorunluluk hali dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi (m. 25, f. 2),

⁴⁵⁴ Ancak, dikkat etmek gerekir ki, Kanunun 297. maddesinin birinci fıkrasında

“İnfaz kurumuna veya tutukevine silâh, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır.”

hükmüne yer verilmiştir. Bu fıkra hükmünde belirtilen fikri içtima halinde, en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı belirlenen cezada belli oranda artırım yapılacaktır. Söz konusu artırma da, cezanın belirlenmesine ilişkin olarak izlenen sürecin bu aşamasında yapılacaktır.

- 7- Hukuka aykırı ve fakat, bağlayıcı emrin yerine getirilmesi (m. 24, f. 2 - 4),
- 8- Sınırın aşılması (m. 27),
- 9- Haksız Tahrik (m. 29).
- 10- Kusurluluğu etkileyen hata halleri (m. 30, f. 3, 4)

Bu nedenlerden bir kısmı, kişinin işlemiş bulunduğu suçtan dolayı *kusurluluğu- nu ortadan kaldırdığı* için, cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulmalarına gerek yoktur. Örneğin, hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi (m. 24, f. 2 - 4), sınırın aşılması (m. 27), cebir veya tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi (m. 28), ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran neden olarak zorunluluk hali (m. 25, f. 2), geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma (m. 34), işlediği fiilin bir haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşmesi (m. 30, f. 4), kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerin maddi şartlarında kaçınılmaz bir hataya düşmesi (m. 30, f. 3) hallerinde kişiye ceza verilmediği için, bu nedenlerin cezanın belirlenmesi sürecinde dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır.

61'inci maddenin beşinci fıkrasında, *kusurluluğu* ve daha geniş ifadeyle ceza sorumluluğunu *azaltan nedenler* dolayısıyla cezanın belirlenmesinde izlenecek sıra gösterilmiştir.

Bu sıralamada ilk önce *haksız tahrik* durumu değerlendirilecektir (m. 29). Kişinin somut olayda kusurluluğu azaltan bir neden olarak haksız tahrikin maddi şartlarında hataya düşmüş olması hali de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Somut olayda haksız tahrikin şartları gerçekleşmediği halde, kişi bu şartların gerçekleştiğini zannederek suç işlemiş olabilir. Kişi, kendi koşulları itibarıyla kaçınılmaz olması halinde, bu hatasından yararlanacaktır. Başka bir deyişle, bu durumda kişinin cezasında haksız tahrik hükümlerine göre indirim yapılacaktır (m. 30, f. 3).

İkinci sırada *yaş küçüklüğü* göz önünde bulundurulacaktır. Ancak, belirtmek gerekir ki, bu bağlamda yaş küçüklüğüne rağmen ceza sorumluluğunun varlığı hali dikkate alınacaktır. Birinci grup yaş küçükleri (m. 31, f. 1) ile algılama veya irade yeteneği gelişmemiş olan ikinci grup yaş küçüklerinin (m. 31, f. 2) ceza sorumluluğu olmadığı için, haklarında ceza tayin edilmeyecektir. Bu yaş küçüklerinin durumu cezanın belirlenmesi bağlamında dikkate alınmayacaktır.

Fiili işlediği sırada yirmibir yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler hakkında da yaş küçüklerine ilişkin sorumluluk rejimi uygulanacağı için (m. 33), cezanın belirlenmesi sürecinde bu kişiler, yaş küçüklüğü bağlamında dikkate alınacaklardır.

Üçüncü sırada, *akıl hastalığı* gelmektedir. Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişinin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır (m. 32, f. 1).

Dolayısıyla, 61'inci maddeye göre cezanın belirlenmesi bağlamda ancak akıl hastalığına rağmen ceza sorumluluğunun varlığı hali dikkate alınacaktır. Başka bir deyişle, maruz kaldığı akıl hastalığı nedeniyle kişinin işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirme yeteneği önemli derecede olmamakla birlikte azalmış olması halinde, hakkında cezaya hükmedilebilecektir (m. 32, f. 2). Dikkat edilmelidir ki, bu durumda kişi işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahiptir.

Bu bağlamda ayrıca kusurluluğu azaltan neden olarak zorunluluk hali göz önünde bulundurulacaktır. Kanunun genel hükümler kısmında kusurluluğu ortadan kaldıran neden olarak zorunluluk hali düzenlenmiştir (m. 25, f. 2). Ancak, Kanunda çeşitli suç tanımlarıyla bağlantılı olarak ayrıca zorunluluk hali hükümlerine yer verilmiştir (m. 92, 147). Bu hükümlerde mahkemeye zorunluluk halini, somut olayın şartlarına göre, kusurluluğu ortadan kaldıran veya azaltan sebep olarak kabul etme hususunda takdir yetkisi tanınmıştır. Bunun sonucunda zorunluluk hali somut olayda kusurluluğu azaltan neden olarak kabul edildiği takdirde, faile verilecek cezada indirim yapılması gerekmektedir. İşte bu indirim, 61'inci maddenin beşinci fıkrasında düzenlenen *kusurluluğu azaltan nedenler* bağlamında yapılmalıdır.

VI. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler

Cezanın belirlenmesi sürecinde, Kanunun suçun özel görünüş biçimlerine ilişkin hükümlerinden sonra, *kusurluluğu azaltan nedenler* dikkate alınacaktır.

61'inci maddenin beşinci fıkrasındaki sıralamaya göre; cezanın belirlenmesi sürecinde, kusurluluğu azaltan nedenlere ilişkin hükümlerden sonra, *cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler* dikkate alınacaktır.

Cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler, şahsi cezasızlık sebepleri ve cezayı ortadan kaldıran şahsi sebepler ayırımına paralel olarak, suçun icrası sırasında mevcut olması veya suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkması bakımından bir ayırıma tabi tutulabilirler.

Suçun icrası sırasında mevcut olan cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler olarak, örneğin Kanunun “*Malvarlığına Karşı Suçlar*” Bölümünde yer alan hırsızlık gibi bazı suçların belli akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişilere karşı işlenmesi halinde, cezada indirim yapılmaktadır (m. 167, f. 2). Keza, bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında örneğin belli akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişi lehine olarak yalan tanıklıkta bulunulması halinde, verilecek cezada indirim yapılabilir (m. 273, f. 1).

Yine, Kanunda belli suçlar bağlamında suç tamamlandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümlerin bir kısmında etkin pişmanlık gösteren kişi hakkında verilecek cezada indirim yapılması öngörülmüştür (m. 93, f. 2; m. 110; m. 168, f. 1).

Bu sebeplerin varlığı halinde, bunlar suçun icrası sırasında mevcut olması veya suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkmasına göre cezanın belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Bir olayda hem suçun icrası sırasında mevcut olan hem de suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkan cezada indirim yapılmasını gerektiren birden fazla neden bulunabilir. Belli akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişilerin malına karşı işlenen hırsızlık suçunda suçun konusunu oluşturan malın geri verilmesi bu ihtimale örnek olarak gösterilebilir.

Keza, belirtmek gerekir ki, Kanunun azmettirmeye ilişkin hükümleri içeren 38'inci maddesinin üçüncü fıkrasında *cezada indirim yapılmasını gerektiren bir şahsi sebebe* ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu husus da, 61'inci maddenin beşinci fıkrasında söz konusu edilen cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler bağlamında değerlendirilmelidir.

VII. Takdiri İndirim Nedenleri

Cezanın belirlenmesi sürecinde son olarak, cezanın bireyselleştirilmesi müessesesi olan *takdiri indirim nedenleri* göz önünde bulundurulacaktır (m. 61, f. 5; m. 62).

Takdiri indirim nedeni olarak “*failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları veya cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri*” göz önünde bulundurulacaktır (m. 62, f. 2). Dikkat edilmelidir ki, takdiri indirim nedenleri Kanunda tadadi olarak gösterilmemiştir.

Bu hususla ilgili olarak, söz konusu madde **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir⁴⁵⁵:

“... *takdiri indirim nedenlerinin neler olabileceği, sınırlı olmamak üzere ve örnekler şeklinde belirlenmiştir. Bunlar, maddenin ikinci fıkrasında failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar olarak belirlenmişlerdir. Bu nedenler, Hükümet Tasarısında temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilecek hususlar arasında gösterilmiştir. Ancak, yapılan değişiklikle, mükerrer değerlendirme yasağı dolayısıyla, bu nedenlerin temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınmaması, sadece takdiri indirim nedenleri olarak göz önünde bulundurulması gereği kabul edilmiştir.*”

Ancak belirtmek gerekir ki, TCK, m. 62, f. 2'de 12.5.2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanunla (m. 1) yapılan değişikliğe göre, “*failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz.*” Keza, “*takdiri indirim nedenleri kararda gerekçeleriyle gösterilir.*”

⁴⁵⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 470.

Takdiri indirim nedenlerinin varlığı halinde cezada ne suretle indirim yapılacağı, 62'nci maddenin birinci fıkrasında gösterilmiştir. Buna göre:

“Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda⁴⁵⁶ birine kadar indirilir.”⁴⁵⁷

⁴⁵⁶ Bu fıkradaki azami indirim oranı beşte birken, 31.3.2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunla (m. 2) altıda bir olarak değiştirilmiştir.

Bu Kanunun TBMM Genel Kurulunda yapılan müzakereleri sırasında verilen söz konusu maddeye ilişkin değişiklik önergesindeki gerekçe şu şekildedir:

“Her ne kadar yeni Türk Ceza Kanununun 62'nci maddesinde failin yararına cezayı hafifletecek takdiri sebeplerin varlığı halinde “diğer cezaların beşte birine kadar indirilebilir.” denilmekte ise de Kanunda öngörülen hapis sürelerinin beşe bölünebilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Uygulamamız da altıda birlik indirim oranını bu güne kadar problemsiz bir şekilde uygulamıştır. Öte yandan takdiri indirim nedenlerinin varlığı halinde, cezada yapılacak olan indirim oranının değiştirilmesinin uygulamada karara bağlanmış pek çok dosyanın lehe hüküm uygulaması nedeniyle yeniden ele alınmasını sonuçlayacaktır. Bu durum, mahkemelerde büyük bir oranda iş yükü artışına neden olacaktır. Belirtilen bu nedenlerle, madde metninde kabul edilen azami indirim oranının altıda bir olarak değiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.”

⁴⁵⁷ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 31.1.2012 tarihli ve E. 2011/4-277, K. 2012/4 sayılı Kararında takdiri indirim nedenlerine ilişkin olarak yer verilen açıklamalar, uygulama bakımından önem arz etmektedir:

“TCK'nın 62. maddesinin ikinci fıkrasında takdiri indirim nedenleri sayıldıktan sonra “gibi” denilmek suretiyle takdiri indirim nedenlerinin yasada sayılanlarla sınırlı olmadığı, aksine bunların örnek olarak sayıldığı açıkça vurgulanmıştır. Burada sayılan “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri” gibi nedenler, uygulamada hâkimi sınırlayıcı değil yol gösterici nitelikteki gerekçelerdir. Bunun sonucu olarak da 5237 sayılı TCK'nın, tıpkı 765 sayılı TCK'da (m. 59) olduğu gibi takdiri indirim nedenleri yönünden sınırlayıcı sistemi değil serbest değerlendirme sistemini benimsediği kabul edilmektedir.

Serbest takdir sisteminin bir gereği olarak da olayda sanık yararına takdiri indirimin uygulanmasını gerektiren nedenlerin varlığını veya yokluğunu belirleme yetkisi yargılamayı yapan hâkime ait olacaktır. Zira yargılama süreci boyunca maddi gerçeğe ulaşma ve adaleti sağlama yolunda çaba harcayan hâkim, sanığı birebir gözlemleyen ve bu bağlamda takdiri indirim nedenlerinin varlığı ya da yokluğunu en iyi tespit edebilecek konumdaki kişidir. Hâkim; “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri”nin yanında, her somut olaya göre değişebilecek ve önceden öngörülemez nedenleri de birlikte değerlendirerek bu hususta hak, adalet ve nesafet kurallarına uygun biçimde uygulama yapacaktır.

Yasa koyucu, hâkime takdiri indirim hükmünün uygulanması konusunda geniş bir takdir yetkisi tanıyarak uygulamada çıkabilecek olan ve önceden öngörülme olanağı bulunmayan çeşitli halleri kapsayacak bir kalıp bulmanın zorluğu karşısında hâkimin bu yetkisini kısıtlamaktan özenle kaçınmıştır.

Ancak hâkimin bu konudaki takdir yetkisi sınırsız değildir. Bütün kararlarda olduğu gibi takdiri indirimin uygulanmasına veya uygulanmamasına ilişkin kararlar da gerekçeli olmalıdır. Bununla birlikte gösterilen gerekçelerin hak, adalet ve nesafet kuralları ile dosya içeriğine uygunluğunun Yargıtay denetimine tabi olacağına da kuşku bulunmamaktadır.

Bu açıklamalar ışığında uyumsuzluk konusu değerlendirildiğinde;

Sabıka kaydında birden fazla geçmiş hükümlülüğü bulunan ve bu sabıkaları nedeniyle hakkında tekerrür hükümleri uygulanması gereken, aşamalarda alınan savunmalarında maddi olayı ısrarla gerçekleşme şeklinden farklı olarak anlatan, yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiğine ilişkin herhangi bir söylem veya eylemi dosya içeriğine yansımayan sanık hakkında, kendisini yargılama sürecinde bizzat gözlemleyen yerel mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmaması, hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmemesi ve verilen cezanın ertelenmemesi yönünde gösterilen gerekçe dosya kapsamı ile uyumlu olduğu gibi, hüküm fıkrasında; *“nedenleri bulunmadığından sanığın cezasından başkaca yasal veya takdiri sebeplerle arttırma veya indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına”*, kararın gerekçe bölümünde ise; *“tüm dosya kapsamına göre de sanık lehine yasal veya takdiri indirim sebeplerinin uygulanmasını gerektirir hiç bir sebep bulunmadığı”* şeklindeki takdiri indirimin uygulanmamasına ilişkin gerekçenin de denetime elverişli, yasal ve yeterli olduğu kabul edilmelidir.”

Ceza Genel Kurulu, aynı gerekçelerle;

“Davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan, adresinden ayrıldığı için zorla da hazır edilemeyen, hakkında yakalama emri çıkarılması sonucunda kamu davasının açılmasından itibaren bir yıldan daha uzun bir süre sonra yakalanan, kolluk görevlilerine kendini “Aydın Canözü” olarak tanıtan ve parmak izi araştırması sonucunda gerçek kimlik bilgilerine ulaşılabilen, çok sayıda sabıkası olup, hükmolunan cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektilmesinde karar verilen ve çeşitli suçlardan arama kayıtları da olan sanık hakkında, yakalandıktan sonra savunmasını tespit eden, tutum ve davranışlarını bizzat gözlemleyen yerel mahkemece hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevirmeme ve ertelememe yönünde gösterilen gerekçeler dosya kapsamı ile uyumlu olduğu gibi, *“Nedenleri bulunmadığından sanığın cezasından başkaca yasal veya takdiri sebeplerle arttırma veya indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına”* şeklindeki gerekçenin de denetime elverişli, yasal ve yeterli olduğu kabul edilmelidir.” (CGK, 31.1.2012, E. 2011/8-280, K. 2012/13);

“Davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan, bu nedenle zorla getirilmesine karar verilen, çok sayıda sabıkası olup, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektilmesine karar verilen sanık hakkında, yakalandıktan sonra savunmasını tespit eden, tutum ve davranışlarını bizzat gözlemleyen yerel mahkemece gösterilen; *“Sebepleri ve koşulları bulunmadığından sanık hakkında başkaca takdiri ve yasal artırım ve indirim nedenlerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına”* şeklindeki gerekçenin, dosya kapsamı ile uyumlu, denetime elverişli, yasal ve yeterli olduğu kabul edilmelidir.” (CGK, 7.2.2012, E. 2011/8-273, K. 2012/19);

TCK’nın 62. “madde(sin)de hakimnin takdiri indirim nedenlerinin varlığı halinde cezada belli oranda indirim yapabileceği düzenlenmiş, ancak takdiri indirim nedenlerinin sınırlı olarak sayılması yerine “gibi” ibaresi de kullanılmak suretiyle, örnekleme kabilinden bazı takdiri indirim nedeni olabilecek hallerden bahsedilmekle yetinilmiştir.

Bu durumda, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak 62. madde uyarınca indirim yapıp yapılmayacağının hakim tarafından serbestçe takdir edileceğinde kuşku bulunmamakta ise de; **bu ifadenin, indirim yapılmasına veya yapılmamasına esas alınan nedenlerin temyiz merciince denetlenemeyeceği şeklinde anlaşılması gerekir.** Nitekim, maddenin son cümlesi, “Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir” şeklinde olup; bu cümle ile 62. maddenin uygulanması veya uygulanmaması açısından **yargıca tanınan takdir hakkının “dayanılan nedenler itibarıyla denetlenebilir nitelikte bir takdir hakkı” olduğu** anlatılmak istenmiştir.

Kaldı ki, 4709 sayılı TC Anayasası’nın 141. ve 5271 sayılı CMK’nın 34. maddesi uyarınca mahkeme kararlarının **gerekçeli** olması zorunludur.

Açıklanan nedenlerle; Yerel Mahkemenin, 5237 sayılı TCK’nın 62. maddesini *“5237 sayılı TCK’nın 62. maddesi uygulamada bir atıfet maddesi olmayıp koşulları mahkeme heyetince oluş-*

VIII. Sonuç Ceza Bakımından Sınırlama

Belirli bir suçla ilgili olarak, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan sonuç cezaya sınırlama getirmek amacıyla TCK'nın 61. maddesine 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla altıncı fıkradan sonra gelmek üzere eklenen yedinci fıkraya göre; “*süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı (61.) madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz.*” Söz konusu fıkranın **gerekçesi** şu şekildedir⁴⁵⁸:

“Kanunun 49'uncu maddesine göre, aksine hüküm bulunmayan hallerde, süreli hapis cezasının alt sınırı bir ay, üst sınırı ise yirmi yıldır. Bu alt ve üst sınır, ilgili suç tanımındaki temel ceza açısından belirlenmiştir. Bu itibarla, 49'uncu madde hükmü, sonuç ceza bakımından bir sınır oluşturmamaktadır. Başka bir deyişle, somut olayla ilgili olarak belirlenen sonuç ceza yirmi yıldan fazla olabilecektir. Ancak, bu durumda belirlenen sonuç cezaya yine de bir sınırlama gereği bulunmaktadır. Böyle bir sınırlama, müebbet hapis cezasında koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken asgari süre bakımından önem taşımaktadır. Bu ihtiyaç nedeniyle, 61'inci maddeye eklenen yedinci fıkra ile, hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı belirlenen sonuç cezanın otuz yıldan fazla olamayacağı kabul edilmiştir.”

IX. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesiyle İlgili Örnekler

Cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi bağlamında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar itibarıyla aşağıdaki örnekler verilmiştir:

Örnek 1. A, tabancayla ateş ederek eşini öldürmek ister. Ancak, eşi yaralanır ise de ölmez.

Bu örnekte, TCK'nın 82. maddesine göre A'nın **ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası** ile cezalandırılması gerekir.

Suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla, bu ceza yerine A'ya 35. maddedeki “*onüç yıldan yirmi yıla kadar*” olan makas arasında belirlenen bir ceza verilecektir^{459,460}.

tuğu kanaatine varıldığı takdirde uygulanan yasa maddesi olması karşısında mahkeme heyetince uygulama koşulları oluşmadığı kanaatine varıldığından sanık hakkında TCK 62. madde hükmünün uygulanmasına yer olmadığına” şeklinde açıklama yapmak suretiyle uygulamadığı ve bu konuda direndiği somut olayda, uygulamama nedenlerinin denetime elverecek şekilde açıkça gösterilmemiş olması yasaya aykırıdır.” (CGK, 7.7.2009, E. 2009/9-62, K. 2009/191),

içtihadında bulunmuştur. Ayrıca bkz. CGK, 14.2.2012, E. 2011/8-275, K. 2012/41; CGK, 27.3.2012, E. 2011/4-253, K. 2012/117; CGK, 27.9.2016, E. 2015/1-606, K. 2016/324.

⁴⁵⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 3.

⁴⁵⁹ Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 24.4.2012 tarihli ve E. 2012/9-86, K. 2012/169 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, kamu görevlileri YA ve AD'ye karşı tasarlanarak kasten öldürme suçu işlenir. Ancak suç teşebbüs aşamasında kalır. Bu nedenle sorumlu tutulan suç ortaklarından YT hakkında yardım eden sıfatıyla aşağıdaki usul ve sıraya göre cezaya hükmedilmiştir:

Örnek 2. A, eşini bir başkasıyla olan ilişkisi nedeniyle, tabancayla ateş ederek öldürmek ister. Ancak, isabet kaydedemez.

Bu örnekte, TCK'nın 82. maddesine göre A'nın **ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası** ile cezalandırılması gerekir.

Suçun teşebbüs aşamasında kalması dolayısıyla, bu ceza yerine A'ya 35. maddedeki *“onüç yıldan yirmi yıla kadar”* olan makas arasında belirlenen bir ceza verilecektir.

A hakkında, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, 35. madde hükümleri uygulanmak suretiyle belirlenen ceza miktarı üzerinden, bu cezanın *“dörtte birinden dörtte üçüne kadarı”* arasında belirlenen bir oranda indirim yapılacaktır (TCK, m. 29, f. 1, ikinci cümle).

Örnek 3. A, sopa fırlatarak eşini yaralamak ister. Ancak, fırlattığı sopa eşine isabet etmez.

Bu örnekte, kasten yaralama suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır. Bu nedenle A hakkında, önce TCK'nın 86. maddesinin **birinci** ve **üçüncü** fıkraları göz önünde bulundurularak bir ceza belirlenecektir.

Bu suretle tespit edilen ceza miktarından, bu cezanın *“dörtte birinden dörtte üçüne kadarı”* arasında belirlenen bir oranda indirim yapılacaktır (TCK, m. 35, f. 2, ikinci cümle).

Örnek 4. A, eşinin yüzüne bir bardakla kezzap atar. Kezzap, eşinin yüzüne isabet ederek, yüzünde sabit iz bırakır.

Sanık YT'nin;

1. “TCK'nın 82/1-(a),(g) maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,”

2. Suç “teşebbüs aşamasında kaldığından TCK'nın 35. maddesi uyarınca 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,”

3. “Yardım eden konumunda olduğundan cezasından TCK'nın 39. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

4. “Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğundan TCK'nın 31/3. maddesi uyarınca cezasından 1/3 oranında indirim yapılarak 5 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına”

hükmedilmiştir.

⁴⁶⁰ “765 sayılı TCK'nın aksine, 5237 sayılı TCK'nın teşebbüsü düzenleyen 35. maddesinde; **teşebbüs halinde cezanın belirlenmesi** ile ilgili olarak “eksik teşebbüs-tam teşebbüs” ayrımına yer verilmemiş, adil ve eşit bir cezalandırma bakımından teşebbüs hareketinin meydana getirdiği zarar veya tehlikenin ağırlığının esas alınması öngörülmüştür.

Buna göre, suça teşebbüs durumunda yargıç, önce cezanın belirlenmesindeki ölçülere göre temel cezayı saptayacak; daha sonra, bu konuya ilişkin hükümdeki sırayı takip ederek teşebbüs hükmünü uygulayacaktır. Bu hüküm uygulanırken de somut olayda ortaya çıkan zarar veya tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak, teşebbüse ilişkin hükümde belirtilen sınırlar arasında bir ceza tayin edilecektir.” CGK, **23.6.2009**, E. 2009/1-8, K. 2009/175.

Bu örnekte, kasten yaralama suçu tamamlanmıştır. Bu nedenle A hakkında, önce TCK'nın 86. maddesinin **birinci** fıkrasındaki alt ve üst sınırlar arasında, 61. maddesinin birinci fıkrasındaki ölçütleri göz önünde bulundurularak, bir ceza belirlenecektir.

Yakıcı özelliğe sahip bulunan kezzap, TCK'nın 6. maddesi hükümlerine göre silah niteliğini taşımaktadır.

Kasten yaralama suçu eşe karşı işlenmiştir.

Bu nedenle, TCK'nın 86. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır (m. 86, f. 3).

Fırlatılan kezzap, eşinin yüzüne isabet ederek yüzünde sabit iz bıraktığı için, olayda kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hali gerçekleşmiştir. Bu nedenle, A hakkında 86. maddenin birinci ve üçüncü fıkraları hükümlerine göre belirlenen ceza, bir kat artırılır (m. 87, f. 1). Ancak bu suretle artırılarak belirlenecek ceza beş yıldan az olamaz (m. 87, f. 1, ikinci cümle)^{461,462}.

⁴⁶¹ Dava konusu olayda sanık “uzun namlulu kaleşnikof tüfeği ile mağdurun ayaklarına doğru ateş ederek, ateşli silah yaralanmasına bağlı sağ tibia ve fibulada çok parçalı kırığa ve yüzde sabit eser niteliğindeki yaralanmaya neden” olur. Bu olayda hukuki sorun, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama fiilinde 5237 sayılı TCK'nın 87. maddesi uyarınca ceza miktarının saptanması yöntemine ilişkindir.”

“5237 sayılı TCY'nın 86/1. maddesinde kasten yaralamanın temel şekli düzenlenmiş olup, anılan fıkra uyarınca, kasten başkasını yaralayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Kasten yaralamanın, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olması halinde ise fail maddenin 2. fıkrası ile cezalandırılacaktır. Maddenin 3. fıkrasında ise beş bent halinde kasten yaralama suçunun ağırlatıcı nedenlerine yer verilmiş olup, fıkradaki bu bentlerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde yaralanmanın niteliğine göre fail hakkında 1. veya 2. fıkralar uyarınca hükmedilen ceza yarı oranında artırılacaktır.

Yasanın 87. maddesinde ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama fiilleri yaptırma bağlanmış olup, maddenin 1. fıkrasında bir kat, 2. fıkrasında iki kat artırımı gerektiren haller, 3. fıkrasında kemik kırılması halinde yapılacak artırım, 4. fıkrasında ise kasten yaralama sonucu ölümün meydana gelmesi hali yaptırma bağlanmıştır. Ancak yasa koyucu 1. ve 2. fıkralarda, 86. maddeye göre hükmolunan cezanın bir ve iki kat artırılması esasını kabul etmesine karşın bununla yetinmemiş, her iki fıkranın son cümlelerinde, artırım sonucu hükmolunabilecek cezaların belirli bir miktardan aşağı olamayacağı esasını da kabul etmiştir.

Bu düzenleme uyarınca, mağdurun ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralanması halinde, öncelikle 5237 sayılı TCY'nın 86/1. maddesi uyarınca aynı Yasanın 61. maddesindeki ölçütler nazara alınarak temel ceza belirlenecek, suçun silahla işlenmesi nedeniyle 1. fıkra uyarınca hükmolunan ceza 3. fıkranın (e) bendi uyarınca yarı oranında artırılacak, yaralanmanın yüzde sabit ize neden olmasından dolayı hükmolunan ceza 87/1-c bendi uyarınca bir kat artırılacak, ancak artırım sonucu hükmolunan ceza beş yıldan az ise, fıkranın son cümlesi uyarınca beş yıla yükseltilecek, artırım sonucu saptanan ceza beş yıldan fazla ise bu takdirde son cümle uyarınca herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.”: CGK, 19.10.2010, E. 2010/3-135, K. 2010/204.

⁴⁶² “Temel ceza 5237 sayılı TCK'nın 86/1. maddesine göre belirlenmelidir. Yani öncelikle 86/1. madde uyarınca 1 yıl ile 3 yıl arasında bir ceza belirlenmesi ve bu cezanın suçun silahla iş-

Örnek 5. A, eşinin yüzüne bir bardakla kezzap atar. Ancak, eşinin korunması sebebiyle bu kezzap, yüzüne isabet etmezse de, ayağının yanmasına sebebiyet verir.

Bu örnekte, kasten yaralama suçu tamamlanmıştır. Bu nedenle A hakkında, önce TCK'nın 86. maddesinin **birinci** fıkrasındaki alt ve üst sınır arasında, 61. maddesinin birinci fıkrasındaki ölçütleri göz önünde bulundurularak, bir ceza belirlenecektir.

Yakıcı özelliğe sahip bulunan kezzap, TCK'nın 6. maddesi hükümlerine göre silah niteliğini taşımaktadır.

Kasten yaralama suçu eşe karşı işlenmiştir.

Bu nedenle, TCK'nın 86. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır (m. 86, f. 3).

Örnek 6. A, eşinin yüzüne bir bardakla kezzap atar. Ancak, eşinin korunması sebebiyle, yüzüne veya vücudunun herhangi bir bölgesine kezzap isabet etmez.

Bu örnekte ise, kasten yaralama suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır. Bu nedenle A hakkında, önce TCK'nın 86. maddesinin **birinci** fıkrasındaki alt ve üst sınır arasında, 61. maddesinin birinci fıkrasındaki ölçütleri göz önünde bulundurularak, bir ceza belirlenecektir.

Yakıcı özelliğe sahip bulunan kezzap, TCK'nın 6. maddesi hükümlerine göre silah niteliğini taşımaktadır.

Kasten yaralama suçu eşe karşı işlenmiştir.

Bu nedenle, TCK'nın 86. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır (m. 86, f. 3).

Suç teşebbüs aşamasında kaldığı için, TCK'nın 86. maddesinin **birinci** ve **üçüncü** fıkraları hükümlerine göre tespit edilen ceza miktarından, bu cezanın “*dörtte birinden dörtte üçüne kadarı*” arasında belirlenen bir oranda indirim yapılacaktır (TCK, m. 35, f. 2, ikinci cümle).

lenmiş olması nedeniyle 86. maddenin 3/e fıkrasına göre yarı oranında artırılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu suretle belirlenebilecek ceza 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 6 ay arasında hapis olabilecektir. Son olarak ta, fiil kemik kırılmasına neden olduğundan 86. maddeye göre belirlenmiş olan 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 6 ay arasındaki cezanın 87/3. madde uyarınca “kırıgın hayati fonksiyonlar üzerindeki etkisi ağır olduğundan” yarı oranında artırılması lazımdır. Şu durumda, sanık hakkında tayin edilecek olan cezanın (takdiri indirim uygulanmadan önce) 1 yıl 6 aydan fazla olması, buna karşılık 4 yıl 9 ayı aşmaması zorunludur. Örneğin, somut olaydaki hükümde olduğu gibi alt sınırdan uygulama yapıldığında 86. maddeye göre 1 yıl 6 ay olarak tespit edilecek cezanın, 87/3. madde uyarınca “kırıgın hayati fonksiyonlar üzerindeki ağır etkisi nedeniyle” en üst oranda (yarı oranında) artırılması durumunda ortaya çıkacak ceza 2 yıl 3 ay haptir. Bu cezadan takdiri indirim nedeniyle 1/6 oranında indirim yapılması halinde ise sonuç ceza tecil ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması müesseselerinin uygulanabilirlik sınırı olan 2 yılın altına, yani 1 yıl 10 ay 15 gün hapse kadar inebilecektir. Buna karşılık, belirtilen iki sınır arasındaki cezayı takdir etme yetkisi Özel Daire veya Ceza Genel Kuruluna değil, Yerel Mahkemeye aittir.”: CGK, 1.4.2008, E. 2008/3-58, K. 2008/71.

Dikkat edilmelidir ki, kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden biri somut olayda gerçekleşmediği için, TCK'nın 87. maddesinin birinci veya ikinci fıkraları hükümleri cezanın belirlenmesinde dikkate alınmazlar. Kastan yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri, ancak somut olayda gerçekleştikleri takdirde, cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilirler.

Örnek 7. A, B'nin kamu görevlisi C'ye karşı görevinin gereklerine uygun davranması dolayısıyla işlediği ve fakat teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme suçuna yardım eden sıfatıyla iştirak eder.

Bu durumda, **kamu görevlisine karşı görevinin gereklerine uygun davranması dolayısıyla işlenmiş olan bir kasten öldürme suçu** söz konusudur. Bu suçun cezası **ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır**. Ancak, bu suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. Bu nedenle **A ve B'ye**, 35. madde hükmüne göre, öldürmek kastıyla işledikleri fiil dolayısıyla *“meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı”* göz önünde bulundurularak, *“onüç yıldan yirmi yıla kadar”* olan makas arasında mesela 20 yıl olarak belirlenen bir hapis cezası verilecektir.

B bu suçun **faili** olduğu için, şayet takdiri indirim nedenlerinden (m. 62) yararlandırılacak ise, bu sebeple yapılacak olan indirim, *“onüç yıldan yirmi yıla kadar”* olan makas arasında belirlenen 20 yıl hapis cezası üzerinden yapılacaktır ve B hakkındaki sonuç ceza bu suretle bulunacaktır.

Buna karşılık, **A**, bu suçun **yardım edeni (şeriki)** olduğu için teşebbüs hükümleri uygulanmak suretiyle *“onüç yıldan yirmi yıla kadar”* olan makas arasında belirlenen 20 yıl hapis cezası üzerinden TCK'nın 39. maddesi hükümlerine isnaden ayrıca bir indirim daha yapılacaktır. Bu suretle A'ya 10 yıl hapis cezası verilecektir. Ancak, 39. maddenin birinci fıkrasının son cümlesi gereğince, bu durumda A'ya verilecek olan hapis cezası *“sekiz yılı geçemez.”* Bu nedenle A'ya iştirak hükümleri uygulanarak ancak **8 yıl** hapis cezası verilebilecektir. A şayet takdiri indirim nedenlerinden (m. 62) yararlandırılacak ise, bu sebeple yapılacak olan indirim, bu 8 yıl hapis cezası üzerinden yapılacaktır ve A hakkındaki sonuç ceza bu suretle bulunacaktır⁴⁶³.

⁴⁶³ “5237 sayılı TCY'nın 61. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırları arasında temel ceza belirlendikten ve maddenin 2, 3 ve 4. fıkralarında belirtilen hallerin bulunması halinde, 1. fıkra uyarınca belirlenen temel ceza üzerinden uygulama yapıldıktan sonra, anılan maddenin 5. fıkrası uyarınca, belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanmak suretiyle sonuç ceza tespit edilecektir.

Somut olayda *suç kanıtlarını gizlemek için insan öldürmeye kalkışma suçuna yardım ettiği* kabul edilen hükümlü Ergün hakkında 5237 sayılı TCY'nın 82/1-h ve 35/2. maddeleri uyarınca 20 yıl olarak belirlenen hapis cezasının, anılan Yasanın 39/1. madde ve fıkrasının son cümlesinde yer alan *“bu durumda verilecek ceza 8 yılı geçemez”* düzenlemesi de dikkate alınmak suretiyle 8 yıla indirilmesi ve takdiri indirim nedeniyle 5237 sayılı TCY'nın 62/1. maddesi

Ekskurs 6. Seri Muhakeme Usulünde Hükmolunacak Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Bağlamında Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerisi

Amerika Birleşik Devletlerindeki soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının şüpheli (müdafii) ile pazarlık yapması yönteminden esinlenilerek düzenlenmiş olan **seri muhakeme usulünde**, CMK'deki (m. 250) düzenleme itibarıyla soruşturma konusu suç dolayısıyla şüpheli hakkında temel cezayı belirleme görevi Cumhuriyet savcısına verilmiştir (m. 250, f. 4). Hatta, bazı noktalarda cezanın bireyselleştirilmesi görevi, soruşturma konusu olan ve kanuni tanımı itibarıyla örneğin üç aydan bir yıla kadar hapis **veya** adli para cezasını gerektiren suçtan dolayı şüpheliye hapis cezası mı yoksa adli para cezası mı verilmesi gerektiğini takdir yetkisi, Cumhuriyet savcısına bırakılmıştır. Her ne kadar bu hususlarda Cumhuriyet savcısı mahkemeden talepte bulunacak ise de; mahkeme, seri muhakeme usulünün uygulanması yönündeki talebi kabul ettiği takdirde, Cumhuriyet savcısının talepten belirlendiği cezanın türü ve temel cezanın miktarı ile bağlı olacaktır. Başka bir ifadeyle, CMK'deki düzenlemede, mahkemeye Cumhuriyet savcısının talepten belirlendiği temel cezanın türü ve miktarında değişiklik yapma yetkisi verilmemiştir.

Seri muhakeme usulünde Cumhuriyet savcısına sadece temel cezayı belirleme yetkisi verilmiş ve cezada talep edilen indirimin **temel ceza üzerinden** yapılacağı kabul edilmiştir. Bu yöntemin, bilahare mahkemenin kuracağı mahkûmiyet hükmündeki sonuç cezanın belirlenmesi bakımından pek çok sorun ortaya çıkardığı bir gerçektir ve bu gerçeklik de fark edilmiştir. 8.7.2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanunla CMK, m. 250, f. 4 ve 9'da yapılan değişiklikler, bu sorunları çözmek yerine, daha da karmaşık hale getirmiştir.

Keza mahkeme, Cumhuriyet savcısının seri muhakeme usulünün uygulanması yönündeki talebini kabul ettiği takdirde, temel cezada yapılacak olan indirimin oranında değişiklik yapma konusunda takdir yetkisine de sahip değildir.

Oysa seri muhakeme usulü kapsamına giren ve seçenек yaptırım olarak hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda, şüpheli hakkında hapis değil, adli para cezasının uygulanması, daha doğru bir yöntem olurdu.

CMK'nin düzenlemesi itibarıyla seri muhakeme usulünün uygulama alanının belirlenmesinde soruşturma konusu suç esas alınmıştır⁴⁶⁴. Bu itibarla mükerrerler

gereğince yapılacak 1/6 oranındaki indirimin bu miktar üzerinden yapılması suretiyle neticeten 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, yasanın 62/1. maddesi uyarınca yapılması gereken indirimin 39. maddenin 1. fıkrası uyarınca 1/2 indirim yapılarak tespit edilmiş bulunan 10 yıl üzerinden yapılmak suretiyle, 8 yıl 4 ay olarak belirlenmesi yasa dışıdır.” CGK, 3.11.2009, E. 2009/1-207, K. 2009/262.

⁴⁶⁴ Seri muhakeme usulünün uygulanabileceği suçlar arasında, iftira suçunun özel bir şekli olan TCK, m. 268'de tanımlanan suçun yer alması, doğru olmamıştır. İftira suçu seri muhakeme usulünün uygulanabileceği suçlar kapsamında sayılmamış iken, bu suçun daha rafine bir şekilde işlenmesinin bu kapsama alınmasının bilimsel ve hukuki izahı bulunmamaktadır.

bakımından da seri muhakeme usulü uygulanabilecektir. Bu durum karşısında, soruşturma konusu suçun seri muhakeme kapsamına girmesi halinde, şayet şüpheli daha önce mahkumiyeti olan birisi (mükerrir) ise, hakkında adli para cezası değil, hapis cezası uygulanmalıdır.

Seri muhakeme usulü kapsamına giren suçtan dolayı Cumhuriyet savcısına temel cezayı belirleme yetkisinin verilmesi, doğru olmamıştır. **Cezayı belirleme ve bireyselleştirme yetkisi, münhasıran mahkemeye aittir.**

Bu itibarla, kanun değişikliği ile, seri muhakeme usulü kapsamına giren suçtan dolayı hükmolunacak cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi sürecinde **temel cezanın alt sınırdan belirlenmesinin** sağlamak gerekir. Cumhuriyet savcısı sadece **sonuç cezada** yapılabilecek azami **indirim** oranı ile ilgili olarak mahkemeye teklifte bulunabilmelidir. **Cezada ne oranda indirim yapılacağını belirleme yetkisini de mahkemeye vermek gerekir.**

X. Mahsup

Hükmün kesinleşmesi üzerine cezanın infazına derhal başlanır. İnfazın erteleneceği haller, 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16 ve devamı maddelerinde gösterilmiştir⁴⁶⁵,⁴⁶⁶. Bu düzenleme karşısında,

⁴⁶⁵ Hapis cezasının infazının;

- a) **hastalık sebebiyle** ertelenmesi, 16. maddede,
- b) **sair çeşitli sebeplere** bağlı olarak hükümlünün talebi üzerine ertelenmesi, 17. maddede, düzenlenmiştir.

⁴⁶⁶ Keza, **mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında bir tereddüdün ortaya çıkması halinde**, bu tereddüdün giderilmesi amacıyla, tereddüt giderilmeye kadar, **mahkum olunan hapis cezasının infazı ertelenebilir veya başlamış olan infaz durdurulabilir.**

5275 s. İnfaz Kanununun 98. maddesinde yer verilen düzenlemeye göre;

“Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir.” (birinci fıkra)

“Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılan başvurular cezanın infazını ertelemez. Ancak, mahkeme olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.” (üçüncü fıkra)

Yeni TCK’nın yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki 5252 s. Kanunun 10. maddesinde de aynı içerikte düzenleme yer almaktadır.

Aynı yönde düzenlemeye 1416 s. mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesinde de yer verilmişti. Söz konusu hükme göre, **“cezanın hesabında tereddüt edilir”** ise, **“mahkeme infazın tehirini veya tatilini emredebilir.”**(f. 1, 3).

Buna göre, infazın mahiyetiyle veya süresiyle bağlantılı olarak bir hukuki sorunun ortaya çıkması halinde, hükümlünün mağduriyetine sebebiyet vermemek için, **cezanın** henüz başlamamış olan **infazı ertelenebilmekte** veya başlamış olan **infazı durdurulabilmektedir.**

hükümlünün başka suçlardan dolayı tutuklu bulunması, kesinleşen mahkumiyet hükmünün infazı bakımından bir erteleme sebebi oluşturmaz.

Bu itibarla, kişinin A suçundan dolayı **tutukluluk hali devam ederken**, B suçundan dolayı hapis cezasına mahkum olması ve bu cezasının kesinleşmesi halinde, kesin hükümle mahkum olduğu hapis cezasının infazına başlanmalıdır. Bu durumda, A suçundan dolayı tutukluluk hali devam etmekle birlikte, kişi cezaevinde A suçundan dolayı tutuklu sıfatıyla değil, B suçundan dolayı mahkum olduğu cezanın infazı bağlamında **hükümlü sıfatıyla** bulunmaktadır. Başka suçlardan dolayı tutuklu olan kişinin B suçundan dolayı kesin hükümle mahkum olduğu hapis cezasının infazına başlanmasıyla, infaz kurumundaki statüsü **hükümlüye** dönüşür. Bu durumda, kişinin yargılaması devam etmekte olan A suçundan dolayı tutuklulukta geçirdiği süre, B suçundan dolayı mahkum olduğu hapis cezasının infazına başlandığı tarih itibarıyla infaz edilmiş sayılır.

Keza belirtmek gerekir ki, **bir mahkumiyet hükmünün kesinleşme tarihinden önceki bir tarihte infazına kayden başlanamaz. İnfaz ancak hüküm kesinleştikten sonra yapılabilir.** Ancak, hüküm kesinleştikten sonra infazına başlanan hapis cezasından, aynı suç nedeniyle veya başka suçlar nedeniyle gözaltında geçirilen ve tutuklu kalınan süreler, mahsup edilebilir.

Kişinin mahkum olduğu hapis cezasının infaz kurumunda çekmesi gereken kısmından, önce bu mahkumiyet hükmünün ilişkin olduğu suçtan dolayı gözaltında geçirdiği ve tutuklu kaldığı süreler mahsup edilir. Bu mahsup işleminden sonra, infaz kurumunda çekilmesi gereken cezanın kalan kısmından, **başka suçlardan dolayı açılan ve halen derdest olan dava dosyalarındaki tutukluluk süreleri** de mahsup edilir⁴⁶⁷.

Önemle belirtmek gerekir ki, **mahsup kişinin mahkum olduğu hapis cezasının ancak infaz kurumunda çekmesi gereken kısmından yapılabilir. Koşullu salıverildikten sonra toplumsal ortamda çekilmesi gereken ceza miktarından mahsup yapılamaz.**

Bu mahsup işleminin sonucuna göre hükümlü hakkındaki (muhtemel) koşullu salıverme tarihini belirlemek gerekir.

Kişi, bir suç nedeniyle hürriyetinden yoksun bırakılmış olmasına rağmen, bilahare hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veya beraat hükmü verilmiş olabilir. Hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veya beraat hükmü verilmiş olan suç nedeniyle hürriyetinden yoksun bırakıldığı süre, kişinin bilahare işlediği suçtan dolayı mahkum olduğu cezadan da mahsup edilebilir.

⁴⁶⁷ Bu bağlamda **yanlış** bir uygulamamıza daha işaret etmek gerekir: Tutuklu olarak yargılamasına devam edilen sanık hakkında hapis cezasına mahkumiyet hükmü kurulmasına rağmen ve tutuklulukta geçen süre mahsup edilse bile kişinin mahkum olduğu cezanın bir kısmını daha infaz kurumunda çekmesi gerektiği halde, sanık mahkumiyet hükmü ile birlikte tahliye edilmektedir. Bu uygulamanın yanlış olduğunu belirtmekle yetinmek istiyoruz.

Mahsup konusunda yeni TCK'nın 63. maddesinde hüküm bulunmaktadır:

*“Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adli para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün beşyüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır.”*⁴⁶⁸

Bu hükmün **gerekçesi** şu şekildedir⁴⁶⁹:

“Maddeyle, mahkûmun suç nedeni ile şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran örneğin tutuklama gibi hâller nedeni ile geçirilen sürelerin mahkûmiyetten indirilmesi esası benimsenmiştir. Böylece teknik anlamda tutukluluk sayılmamakla beraber şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran tedbirlerin tümünün de tutukluluk gibi mahkûmiyet süresine mahsup edilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, madde metninde “hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller” ibaresi kullanılmıştır.

Maddede “hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen” ibaresi yer aldığından hükümlünün mahkûm edildiği suçtan başka bir fiilden dolayı yargılama nedeniyle hürriyetinin sınırlanmış olması hâlinde de mahsubun hangi koşul ile yapılabileceği gösterilmiştir.

Tasarıdaki maddenin ikinci cümlesinde yapılan değişiklikle, adli para cezasına hükmedilmesi durumunda, mahsubun bir gün karşılığı yüz Türk Lirası sayılmak suretiyle yapılacağı kabul edilmiştir.”

Söz konusu 63. maddedeki mahsup hükmü, iki farklı hale özgü bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi, kişinin bir suçtan dolayı hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde gözaltında veya gözlem altında tutulduğu ya da tutuklu kaldığı sürelerin, **aynı suçtan** dolayı mahkum olduğu cezadan mahsup edilmesidir.

Cezadan mahsup edilecek süreler, “*şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiş süreler*”dir; yani kişinin aynı suçtan dolayı gözaltında, gözlem altında veya tutuklulukta geçirdiği sürelerdir⁴⁷⁰.

Buna karşılık kişi hakkında örneğin adli kontrol koruma tedbirine karar verilmiş olması halinde, adli kontrol altında geçirilen süre, hükmolunan cezadan mahsup edilmeyecektir. Bu hususla ilgili olarak, CMK'nın 109. maddesine açık hüküm konulmuştur⁴⁷¹:

⁴⁶⁸ Bu fıkra, 2.3.2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanunla (m. 37) değişiklik yapılarak, mahsup işleminde bir gün karşılığı yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına çıkarılmıştır.

⁴⁶⁹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 470.

⁴⁷⁰ Gözaltına alma ile ilgili olarak, CMK'nın 91. maddesine, gözlem altına alma ile ilgili olarak, 74. maddesine ve tutuklama ile ilgili olarak 100 ve devamı maddelerine bakılmalıdır.

⁴⁷¹ Ünver, TCK'nın 16. maddesi ile 63. maddesi hükümleri arasında bir “çelişki” olduğunu iddia ederken, CMK'nın 109. maddesinin altıncı fıkrası hükmünü gözden kaçırmış olmalıdır (ÜNVER, Ceza Hukuku Dergisi, Ekim 2006, sh. 43).

“Adli kontrol altında geçen süre, şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan mahsup edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen hallerde uygulanmaz.” (f. 6).

Ancak, fıkranın ikinci cümlesinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde gösterilen durumlar, istisnanın istisnası olarak kabul edilmiş ve TCK’nın 63. maddesindeki kurala tekrar geçerlik tanınmıştır. Başka bir deyişle, “*uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla,*” uygulanan tedavi veya muayene süresi, hükmolunan cezadan mahsup edilecektir.

Mahsup işlemi yapılmadan önce kişi hakkında mahkumiyet hükmü kurulur ve mahkumiyet hükmünde belirlenen ceza üzerinden mahsup yapılır.

Şayet mahkum olunan ceza hapis cezası ise, gözaltında, gözlem altında veya tutuklulukta geçirilen süreler, gün ay veya yıl olarak bu cezadan mahsup edilir ve infaz buna göre gerçekleştirilir.

Buna karşılık, adli para cezasına hükmedilmişse; gözaltında, gözlem altında veya tutuklulukta geçirilen süreler, “*bir gün beşyüz Türk Lirası sayılmak*” suretiyle bu cezadan mahsup edilir (m. 63, ikinci cümle).

Kişi hakkında hükmolunan hapis cezası ertelenmiş olsa bile, mahsubun yapılması gerekir. Çünkü, kişi, denetim süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklerle uygun davranmadığı veya yeni bir suç işlediği takdirde, cezasını infaz kurumunda çekecektir.

Kişi hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezası, seçenek yaptırım olarak adli para cezasına çevrilmiş ise; mahsup, adli para cezasından yapılmalıdır.

Kişi hakkında hem hapis hem de adli para cezasına hükmedilmişse, mahsup önce hapis ve bilahare adli para cezasından yapılır.

Mahsup, kural olarak hükmü veren mahkeme tarafından yapılır. Bazı durumlarda mahsup, cezanın infazı aşamasında infazı gerçekleştiren C. savcısı tarafından da yapılabilir. Mahsup dolayısıyla ortaya bir tereddüdün çıkması halinde, C. savcısı İnfaz Kanununun 98. maddesi hükmüne istinaden mahkemeden karar verilmesini isteyebilir.

Keza, söz konusu 63. madde hükmüne göre, kişinin bir suçtan dolayı hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde gözaltında, gözlem altında veya tutuklulukta geçirdiği süreler, bu maddede belirtilen koşulların varlığı halinde, bir **başka suçtan** dolayı hakkında hükmolunan cezadan mahsup edilmektedir. Başka suç nedeniyle gözaltında, gözlem altında veya tutuklulukta geçirilen sürelerin, hükmolunan cezadan mahsup edilebilmesi için, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekir:

a) Kişinin gözaltına veya gözlem altına alındığı ya da tutuklandığı suçtan dolayı hakkında,

- aa) yapılan soruşturma sonucunda C. savcısı tarafından kovuşturmayaya yer olmadığı veya
- bb) açılan davada mahkeme tarafından beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekir.
- b) Kişi, başka bir suç nedeniyle hakkında açılan davada cezaya mahkum edilmelidir.
- c) Ceza mahkumiyetinin sebebini oluşturan suçun, kişi hakkında verilen,
 - aa) kovuşturmayaya yer olmadığı kararının (CMK, m. 172) veya
 - bb) beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı hükmünün (CMK, m. 223, f. 2, 3, 4) kesinleştiği tarihten önce işlenmiş olması gerekir.

Şöyle bir örnekle durum daha iyi açıklanabilir: A, kendisine isnat edilen X suçundan dolayı hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde tutuklanır. A, kendisine isnat edilen Y suçundan dolayı da aynı zamanda veya farklı zamanlarda yargılanır. Tutuklandığı X suçundan dolayı A hakkında yapılan yargılama sonucunda beraat kararı verilir. Buna karşılık, A hakkında Y suçundan dolayı açılan davada yapılan yargılama sonucunda, hapis cezasına hükmolunur. A'nın X suçundan dolayı tutuklu kaldığı sürelerin, hakkında Y suçundan dolayı hükmolunan cezadan mahsup edilebilmesi için; 63. madde hükmüne göre, Y suçunun, X suçundan dolayı verilen beraat hükmü kesinleşmeden önce işlenmiş olması gerekmektedir. Ancak, X suçundan dolayı açılan davadaki beraat kararının, Y suçundan dolayı verilen mahkumiyet kararından önce verilmiş olması şart değildir.

TCK'nın 63. maddesinde yapılan bu düzenleme ile, 6.3.1940 tarihli ve 5/68 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında⁴⁷² benimsenen çözüm biçimi kanunlaştırılmıştır.

Mahsup işleminin yapılabilmesi için, kişinin gözaltına veya gözlem altına alındığı ya da tutuklandığı suçtan dolayı hakkında mutlaka beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekmemektedir. Kişi hakkında gözaltına veya gözlem altına alındığı ya da tutuklandığı suçtan dolayı C. savcısı tarafından kovuşturmayaya yer olmadığı kararının verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi

⁴⁷² Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Ceza Bölümü, I, (1927-1940), Ankara, 1977, sh. 627 vd.

Ancak, işaret etmek gerekir ki, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 31.01.2006 tarihli ve E. 2006/1-4, K. 2006/7 sayılı Kararında, 06.03.1940 tarih ve 5-68 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının "*halen mahsup konusunda geçerliliğini koru*"duğundan söz edilmektedir. Bu ifadenin doğru olmadığını belirtmek gerekir. Bir içtihadın geçerliliğini devam ettirip ettirmemesi söz konusu değildir. Söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararı hukuk sistemimizde varlığını devam ettirmektedir. Yeni TCK'nın 63. maddesi, bu İçtihadı Birleştirme Kararı göz önünde bulundurulmak suretiyle, formüle edilmiştir. Bu nedenle, 06.03.1940 tarih ve 5-68 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının işlevini yitirmedikinden söz edilebilir. Bu durumda söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararı, ancak 63. madde hükmünün yorumlanmasında bir **yorum aracı** olarak işlev görebilir.

halinde de, gözaltında, gözlem altında veya tutuklulukta geçirdiği süre, diğer suçtan mahkum edildiği cezadan mahsup edilecektir. Bu bakımdan 63. maddedeki “*hüküm kesinleşmeden önce*” ibaresini kovuşturmaya yer olmadığı kararlarını da kapsayacak şekilde geniş yorumlamak gerekir.

Bir suçtan dolayı mahkum olunan ceza süresi, gözaltında, gözlem altında veya tutuklulukta geçirilen süreden kısa olabilir. Bu durumda, mahsup fazlası şahsi hürriyetten yoksun kalınan süre, yine 63. maddedeki koşulların varlığı halinde, başka bir suçtan dolayı mahkum olunan cezadan mahsup edilecektir. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz:

A, X suçundan dolayı daha önce hapis cezasına mahkum olur, kesinleşmiş olan cezasının infazı sürecinde koşullu salıverilmeden yararlanır ve denetim süresi içinde Y suçunu işler. A, Y suçundan dolayı hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde belli bir süre tutuklu kalır. Yapılan kovuşturma sonucunda A hakkında Y suçundan dolayı hapis cezasına hükmolunur. A’nın Y suçundan dolayı mahkum olduğu hapis cezasının süresi, bu suçtan dolayı tutuklu kaldığı süreden kısadır. Bu durumda, A’nın Y suçundan dolayı fazla tutuklu kaldığı süre, X suçundan dolayı çekmekte olduğu hapis cezasına ilişkin koşullu salıverilme kararının geri alınması üzerine infaz kurumunda çekmesi gereken cezadan mahsup edilecektir. Çünkü, X suçu, tutuklu kalınan süreden daha kısa süreli hapis cezasına mahkum olunan Y suçundan dolayı verilen hükmün kesinleşmesinden önce işlenmiştir⁴⁷³.

TCK’da, bu genel mahsup hükmünün dışında, başka bir mahsup hükmü daha bulunmaktadır (m. 16). Bu hüküm, milletlerarası ceza hukuku uygulamasında non bis in idem kuralına geçerlilik tanınmayan hallere özgü bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, non bis in idem kuralına milletlerarası ceza hukuku uygulamasında ancak kanunda veya milletlerarası sözleşmelerde açık hüküm bulunan hallerde istisnai olarak geçerlilik tanınmaktadır. Non bis in idem kuralına geçerlilik tanınmayan hallerde işlediği suç dolayısıyla yabancı ülke mahkemelerinde bir cezaya mahkum edilmiş ve hatta bu cezası infaz edilmiş olsa bile, kişi, örneğin TCK’nın 13. maddesindeki koşullar gerçekleştiği takdirde, Türkiye’de aynı suçtan dolayı yeniden yargılanabilecek ve hakkında Türk kanunlarına göre cezaya hükmedilebilecektir. TCK’nın 16. maddesi bu durumda kişinin bu suç nedeniyle yurt dışında mahkum edildiği cezanın infaz edilen kısmının Türkiye’de hükmolunan cezadan mahsup edilmesini düzenlemektedir. Bu nedenle, 16. madde kapsamında mahsuptan söz edebilmemiz için, her iki mahkumiyetin **aynı fiile** ilişkin olması gerekmektedir⁴⁷⁴. Hatta 16. maddeye göre, kişinin, işlediği suç nede-

⁴⁷³ Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 31.01.2006 tarih ve E. 2006/1-4, K. 2006/7 sayılı Kararı, bu hususta ve genel olarak mahsup konusunda ayrıntılı bilgi içermektedir.

⁴⁷⁴ Mesela Türkiye’den ihraç edilen uyuşturucu veya uyarıcı maddenin yabancı ülkede satılması halinde, konuları aynı olsa bile, TCK’da ihraç ve satmak fiilleri ayrı suçlar olarak tanımlandı-

niyle yurt dışında mahkum edilmese bile, başka bir devlette başlatılan soruşturma ve kovuşturma sürecinde gözaltında, gözlem altında veya tutuklulukta geçirildiği süreler de, aynı suçtan dolayı Türkiye’de mahkum edildiği cezadan mahsup edilecektir.

Buna karşılık, yukarıda da açıklandığı gibi, 63. maddedeki mahsuptan söz edebilmek için fiilin aynı olması şart değildir.

Görüldüğü gibi, TCK’nın 16. maddesindeki mahsup hükmüyle 63. maddesindeki mahsup hükmünün düzenledikleri alanlar birbirinden tamamen farklıdır ve düzenlemeleri arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

ğı için, yabancı ülkede bu maddenin satılması nedeniyle gözaltında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen süre Türkiyede ihraç suçu nedeniyle hükmolunan cezadan mahsup edilemeyecektir (TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat: *Uluslararası Ceza Hukuku*, Ankara 2009, sh. 100).

§27. Davanın veya Cezanın Düşmesi

I. Dava Zamanaşımı

Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda, sanık hakkında kovuşturma işlemlerine devam edilmesine engel olan zamanaşımına, yeni TCK’da da benimsenen (m. 66) kavram olarak, “*dava zamanaşımı*” denmektedir.

Dava zamanaşımı, işlenen suçun *cezalandırılabilirliğini ortadan kaldıran bir sebep*⁴⁷⁵ niteliği taşımaktadır. İşlenen fiil, dava zamanaşımının dolmasına rağmen, hukuken tasvip edilmeyen bir fiil ve dolayısıyla, suç olma özelliğini muhafaza eder. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince, bir suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda bu suç açısından cezalandırılabilirlik niteliği artık ortadan kalkmış kabul edildiği için, Devlet, suçu işleyen, suçu işlediğinden şüphelenilen kişi hakkında kovuşturma işlemlerinin yapılmasına devam edilmesinden sarfinazar etmektedir^{476,477}.

Bir suçla ilgili olarak dava zamanaşımı dolmasına rağmen, kanımızca, bu suç, failin işlediği başka bir suçtan dolayı **cezanın bireyselleştirilmesinde** dikkate alınabilir. Zira, belirttiğimiz gibi, işlenen fiil, dava zamanaşımının dolmasına rağmen, hukuken tasvip edilmeyen bir fiil ve dolayısıyla, suç olma özelliğini muhafaza etmektedir⁴⁷⁸.

⁴⁷⁵ “Strafaufhebungsgrund”.

⁴⁷⁶ Türk hukukunda hakim olan görüşe göre, dava zamanaşımı, bir maddi ceza hukuku müessesesidir: KUNTER, Nurullah: *Ceza Hukukunda Zamanaşımı* (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul, 1946, sh. 10. İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/ MAHMUTOĞLU/ ÜNVER, Yaptırım Teorisi(1), sh. 351; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh. 994; ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 273 vd; SOYASLAN, Genel Hükümler, sh. 649. Bu yazarlar, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda devlet “*ceza vermek hakkı*”ndan sarfinazar ettiği için, dava zamanaşımını maddi ceza hukuku müessesesi olduğunu kabul etmektedirler. Ayrıca bkz. TANER, Fahri Gökçen: *Ceza Hukukunda Zamanaşımı*, Ankara, 2008, sh. 33 vd., 52.

Dava zamanaşımını maddi ceza hukuku müessesesi olarak kabul eden eski bir anlayış, dava zamanaşımını *fiilin haksızlık muhtevasını ortadan kaldıran bir sebep* olarak mütalaa etmektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz. MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2, 7. Auflage, Heidelberg, 1989, § 75, kn. 15; JESCHECEK, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 4. Auflage, Berlin, 1988, sh. 811 vd.).

Doktrinde bir diğer görüş ise, dava zamanaşımını gerek maddi ceza hukuku gerek muhakeme hukuku açısından karma nitelikli bir müessese olduğu fikrindedir (Bkz. JESCHECEK, Lehrbuch, sh. 812; DÖNMEZER/ERMAN III, no. 1908, 1909, 2009; CENTEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 659/660).

Dava zamanaşımının maddi ceza hukukuna veya muhakeme hukukuna ilişkin bir müessese olarak kabul edilmesi, bu husustaki kanunî düzenlemelerin zaman bakımından uygulanması açısından farklı sonuçlar doğurmaktadır (Bkz. JESCHECEK, Lehrbuch, sh. 813).

⁴⁷⁷ Bu nedenle, zamanaşımı uygulaması kişinin isteğine bağlı bulunmamaktadır (KUNTER, Ceza Hukukunda Zamanaşımı sh. 21 vd.).

⁴⁷⁸ MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2, § 75, kn. 18. Fahri Gökçen *Taner*, kaynağını yanlış gösterdiği bu görüşümüzü eleştirmektedir (TANER, Fahri Gökçen, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, sh. 125).

Dava zamanasının gereği olarak, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda, suçu işleyen, suçu işlediğinden şüphelenilen kişi hakkında artık kovuşturma işlemlerinin yapılmasına devam edilmez ve “*davanın düşmesine karar*” verilir^{479,480,481}. Nitekim, 5271 sayılı CMK’nın 223’üncü maddesinde aynı esas kabul edilmiştir:

“*Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ... hallerinde, davanın düşmesine karar verilir.*” (f. 8).

Dava zamanasını, yeni TCK’da davanın düşürülmesi kurumlarından biri olarak kabul edilmiştir Birinci Kitap, Üçüncü Kısım, Dördüncü Bölüm “*Dava ve Cezanın Düşürülmesi*” başlığını taşımaktadır.

Bu itibarla, kanımızca, dava zamanasının dolduğundan bahisle kamu davasının açılmasından sarfınazar edilemez. Dava zamanasını dolmuş olduğu kanaatine varılsa bile, kamu davası açılmalıdır. Kamu davası açıldıktan sonra mahkeme, davanın düşmesine karar vermelidir⁴⁸².

Dava zamanasının dolmuş kabul edilebilmesi için geçmesi gereken süreler, suç için kanunda öngörülen cezanın miktarına göre farklılık arz etmektedir.

Dava zamanasına ilişkin süreler Kanunun 66’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiştir:

«*Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası;*

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,

⁴⁷⁹ Ancak belirtmek gerekir ki, müşterek yazarı olduğum *Yaptırım Teorisi* isimli kitabın meslektaşım *Mahmutoğlu* tarafından yazılan zamanasına ilişkin kısmında, dava zamanasının dolması durumunda sanık hakkında “*beraat*” kararı verilmesi gerektiği yönünde görüş dermen edilmiştir (İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ ÖZGENÇ/SÖZÜER/ MAHMUTOĞLU/ÜNVER, *Yaptırım Teorisi*(1), sh. 351). Bu düşüncelerden özellikle dava zamanasının dolması durumunda beraat kararının verilmesi gerektiği yönündeki görüşe iştirak etmediğimizi ifade etmek gereğini hissetmekteyim. Çünkü, beraat, suç şüphesi altında bulunan kişinin suç işlemediğinin, kişinin gerçekleştirdiği davranışın suç oluşturmadığının sabit görülmesi üzerine mahkeme tarafından verilen bir karardır. Beraat kararı, ancak bir haksızlığın söz konusu olmadığı durumlara, yani olayda en azından bir hukuka uygunluk sebebinin mevcut olduğu hallere münhasır kılınmalıdır. Çünkü, bu hallerde kişi haklıdır ve kendisine hiçbir hukuki müeyyide tatbik edilemez. Beraat (“*berâet*”), bir haksızlık iddiasından temiz, ilişiksiz çıkmayı, aklı, arılığı, aklanmayı ifade etmektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, *Suçun Yapısında Kusur*, sh. 130/131).

⁴⁸⁰ Dava zamanasının dolması durumunda zamanasına uğrayan suçla ilgili olarak fail hakkında ceza tayin edilemeyeceği gibi, tedbire de hükmedilemez (MAURACH/GÖSSEL/ ZIPF, *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2*, § 75, kn. 18).

⁴⁸¹ *Kunter*, dava zamanasının dolmasının “suçun düşmesi” sonucunun doğacağı fikrindedir: KUNTER, *Ceza Hukukunda Zamanasını* sh. 44.

⁴⁸² *Kunter*, soruşturma evresinde dava zamanasının dolduğunun anlaşılması halinde “ademi takip (takipsizlik, kovuşturmayaya yer olmadığı) kararı” verilmesi gerektiği fikrindedir: KUNTER, *Ceza Hukukunda Zamanasını* sh. 28.

- b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,
 - c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
 - d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,
 - e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,
- Geçmesiyle düşer.»*

Ancak, Kanunda çocukların işledikleri suçlarla ilgili olarak zamanaşımı süresinin belirlenmesi bakımından özel bir hükme yer verilmiştir:

“Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.” (m. 66, f. 2).

Türk Ceza Kanunu sisteminde dava zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde **soyut ceza** esas alınmaktadır. Başka bir deyişle, belli bir suça ilişkin olarak dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, o suçun *kanundaki ceza miktarı* göz önünde bulundurulmaktadır. 7.5.1947 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında da bu prensip ifade edilmiştir:

«Türk Ceza Kanunu dava zamanaşımının hesap edilmesinde hükmedilecek cezayı esas tutmamış; yalnız, o suçun istilzam ettiği cezayı göz önünde bulundurmuştur.

*Suçun istilzam ettiği ceza esas tutulmuş olunca, mahkemenin de bu esası takip etmesi ve (dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde) vereceği cezayı değil, kanun maddesinde yazılı cezayı nazara alması icap eder.»*⁴⁸³

Doktrinde bir görüş, Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında ileri sürülen bu düşünceyi benimsemektedir⁴⁸⁴.

⁴⁸³ Yarg. İBK, 7.5.1947, E. 1947/3, K. 1947/15 (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Ceza 3, İkinci bası, Ankara, 1984, sh. 74 vd.). Ayrıca bkz. Yarg. İBK, 3.6.1942, E. 1941/36, K. 1942/15 (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Ceza 2, İkinci bası, Ankara, 1984, sh. 194 vd.); CGK., 21.11.1994, 8-273/293 (Taşdemir, Kubilay: *Ceza Davalarında Zamanaşımı*, Ankara, 2001, sh. 58).

⁴⁸⁴ İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Yaptırım Teorisi(1), sh. 356; ÖNDER, Genel Hükümler III, sh. 278 vd.; ayrıca bkz. CENTEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 661/662. *Taşdemir*’in kitabında bu konuda çelişkili açıklama mevcuttur (TAŞDEMİR, Ceza Davalarında Zamanaşımı). Kitabın bir sahifesinde dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde “soyut cezayı değil, suçluyla verilmesi gereken cezayı esas alması nedeniyle yasamızın belirlediği sistem yerindedir” denirken (sh. 4); diğer bir sahifede soyut ceza sistemini benimseyen Yargıtay’ın görüşünün yerinde olduğu ifade edilmektedir (sh. 6).

Yeni TCK'da da aynı düşünce hakim olmuştur:

Dava zamanaşımı süresinin “*belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır.*” (m. 66, f. 4).

Ancak, “*dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de göz önünde bulundurulur.*” (m. 66, f. 3).

Buna göre, zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, suç için kanunda öngörülen **cezanın üst sınırı** esas alınacaktır. Ancak, somut olayda faile daha ağır ceza verilmesini gerektiren nitelikli hallerin varlığı durumunda, dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde bu haller de göz önünde bulundurulmalıdır.

Başka bir deyişle, bu sistemde, zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, o suçla ilgili olarak **hükmedilmesi mümkün olan en yüksek ceza** miktarı esas alınmaktadır⁴⁸⁵.

Ancak örneğin yaş küçüklüğü dolayısıyla cezada yapılacak olan indirim miktar veya oranları, zamanaşımı süresinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz. Keza, suçun müteselsilen işlenmesi durumunda, zincirleme suç dolayısıyla ceza miktarında yapılacak olan artış oranı, zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Yine, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması halinde, dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde bu durum göz önünde bulundurulmaz. Aynı değerlendirmemiz, haksız tahrik açısından da geçerlidir.

Yeni TCK'nın sisteminde, **dava zamanaşımı süresinin başlangıcı** açısından da bir özellik söz konusudur:

“Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs hâlinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bırktığı günden itibaren işlemeye başlar.” (m. 66, f. 6).

Bu itibarla, örneğin zincirleme suç hükümlerinin uygulanabildiği durumlarda dava zamanaşımı süresi, son suçun işlendiği günden itibaren işlemeye başlar⁴⁸⁶.

⁴⁸⁵ Ceza Genel Kurulu'nun **4.12.2012** tarihli ve E. 2012/6-1247, K. 2012/1842 sayılı kararında bu bağlamda yer alan açıklamalar önem taşımaktadır:

5237 s. TCK'nın sisteminde, “**nitelikli haller açısından kanun koyucunun tercih ettiği yaptırım sistemi dikkate alınmaksızın, ister bağımsız bir yaptırım öngörülmüş olsun, isterse belirli bir oran dahilinde artırım yöntemi tercih edilmiş olsun, zamanaşımı süreleri daha ağır cezayı gerektiren tüm nitelikli haller dikkate alınarak belirlenmelidir.**”

⁴⁸⁶ Oysa Yargıtay Ceza Genel Kurulu, TCK'nın 66. maddesinin altıncı fıkrası hükmünü görmezlikten gelerek, zincirleme biçimde işlendiği kabul edilen iki hırsızlık suçundan birincisi ile il-

Hukuk sistemimizde, bazı suçların belli şartlar altında işlenmesi durumunda dava zamanaşımının işlemeyeceği kabul edilmiştir. Buna göre, TCK'nın “*İkinci Kitabının Dördüncü Kısımında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde dava zamanaşımı uygulanmaz.*” (m. 66, f. 7). Keza, soykırım ve insanlığa karşı suçlar ile bu suçları işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma suçlarından dolayı (dava) zamanaşımının işlemeyeceği kabul edilmiştir (m. 76, f. 4; m. 77, f. 4; m. 78, f. 3). Aynı şekilde, işkence suçu ile ilgili olarak da (dava) zamanaşımı hükmü uygulanmayacaktır (m. 94, f. 6)⁴⁸⁷.

Yeni TCK'nın 66. maddesinin beşinci fıkrası, 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla (m. 8) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.”

Yapılan bu değişikliğin **gerekçesi** şudur⁴⁸⁸:

“Yargılamanın yenilenmesi gibi aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, zamanaşımına açıklık getirmeye yönelik olarak bu fıkra metninde değişiklik yapılmıştır. Bu durumlarda, dava zamanaşımı süresi, tekrar yargılama konusu suç bakımından belirlenecektir. Tekrar yargılama konusu suça ilişkin zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi de, bu husustaki talebin mahkemece kabul edildiği tarih olacaktır. Tekrar yargılama konusu suça ilişkin zamanaşımı süresi bakımından, maddenin birinci fıkrasındaki süreler dikkate alınacaktır. Bu düzenlemeyle güdülen asıl amaç, yeniden yargılama söz konusu olan hallerde, bu nedenle dava zamanaşımı süresinin dolduğundan bahisle yargılamaya son verilmesi yönündeki taleplerin önüne geçmektir.”^{489 490}

gili olarak dava zamanaşımı dolduğundan bahisle, bu suçla ilgili olarak düşme kararının verilmesi ve bu suçun zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaması gerektiği yönünde içtihatla bulunmuştur (CGK, **20.3.2012**, E. 2011/2-433, K. 2012/108; CGK, **28.02.2012**, 2010/2-287, K. 2012/58).

Yanlışığı aşıkâr olan bu kararlarla ilgili olarak başka söze hacet bulunmamaktadır.

⁴⁸⁷ Alman hukukunda “soykırım (genosit) suçu” (Alman CK, § 22a) açısından hem dava zamanaşımı hem de infaz zamanaşımı kabul edilmemiştir. Buna karşılık kasten öldürme suçunun nitelikli şekli (“Mord”: Alman CK, § 211) açısından sadece dava zamanaşımı kabul edilmiştir (Bkz. Alman CK, § 78, f. 2; § 79, f. 2). Keza, hangi suç sebebiyle olursa olsun, mahkûm olunan müebbet hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili olarak infaz zamanaşımı kabul edilmemiştir (Bkz. Alman CK, § 79, f. 2).

⁴⁸⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 3.

⁴⁸⁹ Hukuk uygulamamızda, Yargıtay ceza dairesinin verdiği onama kararı ile kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmüyle ilgili olarak bilahare Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz kanun yoluna (CMK, m. 308) başvurması halinde, zamanaşımı bakımından bir sorun ortaya çıkmıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, TCK, m. 66, f. 5 hükmünün yargılamanın yenilenmesi haline özgü olduğunu kabul ederek, bu gibi durumlarda, Yargıtay ceza dairesinin onama kararı ile dava zamanaşımının durduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı üzerine duran dava zamanaşımının durduğu andan itibaren işlemeye başladığı yönünde içtihatla bulunmuştur:

*“Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 21.06.2011 tarihli ve 94-133; 22.11.2011 tarihli ve 203-238 sayılı kararlarında; Yargıtay ilgili Ceza Dairesince bir mahkûmiyet hükmü onanmakla kesinleşeceğinden, kesinleşme anına kadar işleyen dava zamanaşımının bu aşamada sona ereceği, bu karara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yapılan incelemede, Ceza Genel Kurulunca itirazın kabulü hâlinde, **Özel Daire onama kararı ile Ceza Genel Kurulunun karar tarihi arasında geçen sürenin, dava zamanaşımının hesaplanmasında göz önünde bulundurulmayacağı, ancak itirazın kabulü üzerine dosyanın derdest hâle gelmesi nedeniyle yargılamaya devam edildiğinde, Ceza Genel Kurulunca itirazın kabulü tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürenin işlemeye devam edeceği** ve dava zamanaşımının buna göre hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.”* Yargıtay CGK, 15.10.2019, E. 2016/432, K. 2019/603; Yargıtay CGK, 11.12.2018, E. 2015/96, K. 2018/623; Yargıtay CGK, 28.3.2017, E. 2013/192, K. 2017/204; Yargıtay CGK, 20.12.2016, E. 2014/196, K. 2016/2107. Ayrıca bkz. Yargıtay CGK, 29.3.2016, E. 2014/749, K. 2016/158; Yargıtay CGK, 24.2.2015, E. 2013/343, K. 2015/13.

Keza, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kabulüne göre, TCK, m. 66, f. 5 hükmünün *“kanun yararına bozma kararı sonrasında devam edilen yargılamalar yönünden uygulama yerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.*

*... taraflara usulüne uygun şekilde tefhim veya tebliğ edilen hüküm, temyiz edilmemesi hâlinde kesinleşmekte ve kesinleşme anına kadar işleyen dava zamanaşımı, bu aşamada sona ermektedir. Ancak diğer olağanüstü yasa yollarında olduğu gibi kanun yararına bozmada da dava zamanaşımına ilişkin hükümler ancak yasanın açıkça izin verdiği hâllerde uygulanabileceğinden, kanun yararına bozma talebi üzerine yapılan incelemede, Yargıtay ilgili dairesince yerel mahkeme hükmünün kanun yararına bozulmasına karar verildiği durumda, **yerel mahkeme hükmünün temyiz edilmeksizin kesinleştiği tarih ile Yargıtay ilgili dairesinin karar tarihi arasında geçen sürenin dava zamanaşımının hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaması gerektiğinin kabulü zorunludur. Ancak yerel mahkeme hükmünün kanun yararına bozulması üzerine dosyanın derdest hâle gelmesi nedeniyle yargılamaya devam edildiğinde Yargıtay ilgili dairesinin kanun yararına bozma kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere süre işlemeye devam edeceğinden dava zamanaşımı buna göre hesaplanmalıdır.”** Yargıtay CGK, 21.1.2020, E. 2017/618, K. 2020/16.*

Aynı sorun, 15.7.2020 tarihinden önce yapılan istinaf incelemesiyle kesinleşen belirli mahkûmiyet hükümleriyle ilgili olarak bilahare 24.11.2021 tarihli ve 7343 sayılı Kanunla (m. 15) temyiz kanun yolunun açılması üzerine ortaya çıkmıştır. Bu tarihten (15.7.2020 tarihinden) önce kesinleşen hükümlerle ilgili olarak artık dava zamanaşımından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Ancak, bilahare yürürlüğe giren kanunla daha önce kesinleşmiş olan hükümlerle ilgili olarak yeniden kanun yolu açılmıştır. Bu kanun yolunun açılması üzerine başlayan yargılama sürecinde dava zamanaşımı bakımından nasıl bir yol izleneceği hususunda Yargıtay 5. Ceza Dairesi Sayın Başkanının sorusu üzerine kendilerine sunduğum bilgi notunda aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir:

Kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü ile ilgili olarak yeni kanun yolunun açılması üzerine ortaya çıkan dava zamanaşımı sorunu bağlamında iki şekilde düşünülebilir.

Birinci alternatif: Dava zamanaşımının durmasına ilişkin hükümleri göz önünde bulundurarak, hükmün kesinleştiği anda durduğu kabul edilen dava zamanaşımının 7343 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durduğu yerden işlemeye başladığı düşünülebilir.

İkinci alternatif: TCK, m. 66, f. 5’deki yargılamanın yenilenmesi ile ilgili hükmü, kıyas yoluyla uygulamaktır. Bu durumda dava zamanaşımını 7343 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden işletmek gerekir.

II. Dava Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi

Yeni TCK'nın 67. maddesinin birinci fıkrasında **dava zamanaşımının durması** düzenlenmiştir. Bu hükümle dava zamanaşımının hangi hallerde duracağı belirlenmiştir:

“Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılincaya kadar dava zamanaşımı durur.”

Maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında ise **dava zamanaşımının kesilmesine** ilişkin hükümler yer almaktadır:

“Bir suçla ilgili olarak;

- a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,*
- b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,*
- c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,*

Yargıtay ceza dairesinin yaptığı temyiz incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesinin hükmüyle ilgili olarak onama kararı vermesi halinde de hüküm kesinleşmektedir. Bilahare bu onama kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yoluna gitmesi halinde, nasıl bir yol izleneceği konusundaki Yargıtay Ceza Genel Kurulunun içtihadını da dikkate alarak, birinci alternatif çözüm benimsenebilir.

⁴⁹⁰ Anayasa Mahkemesi'nin 29.2.2024 tarihli ve BB 2020/3703 sayılı kararına (RG: 24 Temmuz 2024-32611) konu teşkil eden olayda, PKK terör örgütüne mensup olduğu kabul edilen X, kolluk görevlileri tarafından silahla vurularak yaralanır ve kaldırıldığı hastanede 30.5.2004 tarihinde ölür.

Bu olay dolayısıyla yapılan yargılama sonunda, Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, X'in ölümüne sebebiyet veren silahla atışı gerçekleştiren kolluk görevlisi A'nın **meşru savunma** halinde olduğu kabul edilerek **beraatine** hükmedilmiş ve bu hüküm, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanarak, 5.3.2009 tarihinde kesinleşmiştir.

X'in babasının başvurusu üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu olay bağlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının madde ve usul boyutu itibarıyla ihlal edildiğine ve bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başvuruca 50.000 AVRO tazminat ödemesine hükmetmiştir (29.5.2018, 54915/09). Bu para, kanuni faiziyle birlikte 2018 yılı içinde başvurucaya ödenmiştir.

Başvurucu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararına istinaden Adana Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, bu olayla ilgili olarak **yargılamanın yenilenmesi** talebinde bulunmuştur. Mahkeme, CMK'nin “311 ve 314. maddelerinde yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin tahdidi olarak sayıldığı, talep dilekçesinde bu hususlardan herhangi birine dayanılmadığı, AIHM kararının tazminata ilişkin olduğu, ...” gerekçeleriyle bu talebi reddetmiştir. Bu karara yapılan itiraz da reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, bu olayda **dava zamanaşımının dolduğu ve bu nedenle yargılamanın yenilenmesinin mümkün olmadığı** gerekçesiyle, söz konusu başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı **hukuka aykırıdır**. Yüksek Mahkeme, bu kararı verirken TCK, m. 66, f. 5 hükmünü göz ardı etmiştir.

d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkumiyet kararı verilmesi, hâlinde, dava zamanaşımı kesilir.” (f. 2)

“Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması hâlinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.” (f. 3)

“Kesilme hâlinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.” (f. 4)

Hükümet Tasarısında dava zamanaşımının kesilmesi hususunda hüküm bulunmamaktaydı. TBMM Genel Kurulunda madde hakkında yapılan görüşmeler sırasında (14.9.2004), İktidar ve Anamuhalefet Partisine mensup Milletvekilleri tarafından, söz konusu maddeye dava zamanaşımının kesilmesine ilişkin hükümler ilavesi yönünde bir değişiklik önergesi verilmiştir. Bu önerge üzerine, Meclis'te Grubu bulunan iki Siyasi Partinin uzlaşmasıyla, madde son şekliyle kabul edilmiştir. Bu değişikliğin gerekçesi, önerge metninde şu şekilde ifade edilmiştir:

“Her ne kadar Tasarı metninde dava zamanaşımı süreleri uzun tutulmuş ise de; Tasarının kanunlaşması hâlinde, bunun yürürlüğe gireceği tarihinden önce işlenmiş ve henüz kesin hükümle sonuçlanmamış olan davaların büyük bir çoğunluğunun zamanaşımına uğraması sonucuyla karşılaşılabacaktır. Bu durum, bazı suçlular açısından bir nevi af sonucunu doğuracaktır. Bu sonuç, özellikle, dava zamanaşımı sürelerinin dolma eşğine yaklaşmış olan hâlen derdest bütün yolsuzluk ve “banka hortumlama” davalarının sanıkları açısından doğacaktır. Belirtilen nedenlerle, Tasarı metninde dava zamanaşımının kesilmesine ilişkin düzenleme yapılmasına büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.”

Yeni TCK'nın sisteminde, dava zamanaşımı süresinin kesilmesinde **nesnel ölçüt** esas alınmıştır. Başka bir deyişle, kesme sebebinin varlığı halinde, dava zamanaşımının suça ilgili olarak kesildiğini kabul etmek ve fakat bunu ilgili suç ortağına özgü kesilme olarak mütalaa etmemek gerekir^{491, 492}.

⁴⁹¹ Ancak, belirtmek gerekir ki, hukuk uygulamamızda, nesnel ölçüyü sınırlandıran, dava zamanaşımını kesen sebeplerin şüpheli ve sanıklardan bir kısmıyla sınırlı olarak etki doğurduğu yönünde içtihatlar geliştirilmiştir. Bu konudaki önemli örneği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun **24.12.2019** tarihli ve E. 2016/69, K. 2019/714 sayılı Kararı oluşturmaktadır.

Bu Karara konu teşkil eden olayda; bir eğlence alanında bulunan hareketli eğlence aracına binen bir kısmı çocuk çok sayıda kişi, harekete geçtikten bir süre sonra aracın raydan çıkarak devrilmesi sonucu yaralanırlar.

Bu olay dolayısıyla, eğlence alanının işletmecisi A ile devrilen eğlence aracının kiralayanı B hakkında çok sayıda kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet verme suçunu işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda, A ve B, birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet verme suçundan dolayı mahkum edilmiştir. Yargıtay 12. Ceza

Dairesi, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda, bu mahkumiyet hükmünün onanmasına karar vermekle birlikte, söz konusu eğlence aracının sahibi C'nin de bu olaydan ve gerçekleşen yaralanmalardan sorumlu olduğunu değerlendirmesinde bulunarak C hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiği yönünde karar vermiştir. Bu karara istinaden yapılan suç duyurusu üzerine C hakkında da birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet verme suçundan dolayı kamu davası açılmıştır. İlk Derece Mahkemesi bu davada, dava zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle, düşme kararı verilmiştir. Ancak, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda, söz konusu olayda dava zamanaşımının dolmadığını kabul ederek, C hakkında verilen düşme kararının bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aşağıdaki gerekçe ile bu bozma kararına itiraz etmiştir:

“Sanık (C) hakkında önceden resmî olarak yapılmış herhangi bir soruşturma kovuşturma ya da takipsizlik veya benzeri bir işlem bulunmadığı 5237 sayılı TCK'nın sisteminde, dava zamanaşımı süresinin kesilmesinde nesnel ölçüt esas alındığı ileri sürülmüş ise de, sanığın işlenen taksirle yaralama suçuna iştirakinin söz konusu olmadığı icrai herhangi bir eyleminin bulunmadığı ve sanığın sadece mal sahibi olmasından kaynaklanan kusur sorumluluğu dışında bir iştirakinin bulunmadığı kabul edildiğinde, 765 sayılı TCK'nın 106. maddesinin etkisiyle sanıklar (A) ve (B) hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının TCK 67/2-d maddesi kapsamında zamanaşımını kesen usulî muamele olarak kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, aşağıdaki **gerekçe** ile, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının kabulüne karar vermiştir:

*“... TCK'nın 40. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir." şeklindeki hüküm uyarınca **taksirli suçlarda iştirak ilişkisi mümkün olmadığından**, anılan Kanun'un 22. maddesinin dört ve beşinci fıkralarına göre herkes kendi kusurundan dolayı ve kusuruna göre sorumlu olacaktır.*

...

Dava zamanaşımını kesen nedenler ... mülga 765 sayılı TCK'nın 104. maddesinde, yakalama, tevkif, celp veya ihzar müzekkereleri, sorgu, son soruşturmanın açılması kararı veya iddianame ile dava açılması olarak belirtilmiş olup, kesen nedenlerin iştirak hâlinde suç işleyen sanıklar yönünden sirayeti ise anılan Kanun'un 106. maddesinde; *“Bir suçtan dolayı yapılan ve müruru zamanı kesen muameleler o suçlarda her ne suretle olursa olsun iştiraki olup da aleyhlerinde takibat veya tahkikat yapılmamış olan kimseler hakkında dahi müruru zamanı keser.”* şeklinde düzenlenmiştir.

... 5237 sayılı TCK'da ise dava zamanaşımını kesen nedenler 67. maddede düzenlenmiştir. ... **Mülga 765 sayılı TCK'nın 106. maddesinde yer alan düzenleme ise 5237 sayılı TCK'da yer almamıştır.**

...

Dava zamanaşımını kesen nedenler TCK'nın 67. maddesinin ikinci fıkrasında, bir suçla ilgili olarak; şüpheli veya sanıklardan birinin Cumhuriyet savcısı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi, şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi ve sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi olarak belirtilmiştir. Dava zamanaşımının kesilme nedenleri sayılırken madde metninde kullanılan *“Şüpheli veya sanıklardan birinin”, “Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında”, “Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa”* ibarelerinden dolayı 5237 sayılı TCK'da *“Dava zamanaşımının sirayeti”* ilkesinin benimsendiği ve öznel kriter dışlanarak **nesnel kriter** esas alındığı için suç tarihinden itibaren dava zamanaşımının fail bazında değil de fiile bağlı olarak ortak hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle iştirak hâlinde bir suç işlendiği takdirde şeriklerden biri hakkında dava zamanaşımını kesen işlemler yapılmış ise haklarında madde metninde sayılan işlemler yapılmış veya yapılmamış olan şerikler hakkında da dava zamanaşımı süresi kesilmiş olacaktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.03.2012 tarihli ve 241-114 sayılı kararı ile 31.01.2012 tarihli ve 243-7 sayılı kararında, 5237 sayılı TCK'da dava zamanaşımının sirayeti konusunda fiile bağlılığı

esas alan nesnel ölçütün kabul edildiği, iştirak hâlinde suç işleyen sanıklardan bir kısmı hakkında verilen mahkûmiyet kararının tüm sanıklar için dava zamanaşımını keseceği vurgulanmıştır.

...

... iştirak hâlinde suç işleyen faillerden bir kısmı hakkında verilen mahkûmiyet kararının tüm failler için dava zamanaşımını keseceğine ilişkin kuralın, ancak kanunda açıkça düzenlenen hâllerde cezalandırılacağına öngörülmesi nedeniyle, istisnai bir niteliğe ve kendine özgü bir yapıya sahip taksirli suçlar bakımından ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. ... **taksirle işlenen suçlarda iştirak mümkün değildir.** 765 sayılı TCK'da açıkça ifade edilmeyen bu koşula, yukarıda da ifade edildiği gibi 5237 sayılı TCK'nın 40. maddesinin birinci fıkrasında açıkça yer verilmiştir. Bu nedenle, **birden fazla kişinin fail olduğu taksirli suçlarda sanıklardan biri veya birkaçı hakkındaki mahkûmiyet hükmünün diğer sanıklar için dava zamanaşımını keseceğinden söz edilemeyecektir.** Ulaşılan bu sonuç, **şikâyetin bölünmezliği** ilkesinin taksirli suçlar bakımından aranmayacağına ve birden fazla faili bulunan taksirli suçlarda failler arasında menfaat çatışması ayrıca değerlendirilmeyeceğine ilişkin Özel Daire uygulamaları ile uyum içerisindedir. TCK'nın 22. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkesin kendi kusurundan dolayı sorumlu tutulacağı kuralına uyulmayarak iştirak hâlinde işlenen suçlarda faillerden biri hakkındaki mahkûmiyet kararının diğer failler hakkında da zamanaşımını keseceği yönündeki kabul, taksirli fiilden esasen sorumlu tutulmaması gereken faillerin uzun süre yargılama tehdidi altında tutulmaları sonucunu doğuracak, bu husus ise **belirlilik ilkesinin** yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan "adil yargılanma" hakkının unsurlarından birini oluşturan makul sürede yargılanma hakkının **ihlâl**ine sebebiyet verebilecektir."

Bu Kararla ilgili muhtasar hukuki değerlendirmemiz: Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu kararına katılmamız, mümkün değildir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, TCK'nın suça iştirake ilişkin hükümlerinin taksirli suçlar bakımından uygulanamaması, taksirle işlenen fiilin iştirak hâlinde işlenemeyeceği sonucuna bizi götürmez. Dolayısıyla, bağlılık kuralına ilişkin TCK, m. 40 hükümlerinin zamanaşımı bağlamında gerekçe itiraz edilmesi, doğru olmamıştır. Keza, konunun belirlilik ilkesiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca, C hakkında bilahare dava açıldığı için, makul sürede yargılanma hakkının da ihlalden söz edilemez. Makul sürede yargılanma hakkı, soruşturma ve özellikle kovuşturma başladıktan sonra davanın makul sürede karara bağlanmasını gerekli kılmaktadır. İşlenen somut bir suç bakımından şüpheli olduğu bilahare anlaşılan kişi hakkında bu şüphe üzerine başlatılan soruşturma ve kovuşturmanın ileri bir tarihte yapılması, makul sürede yargılanma hakkının ihlali olarak değerlendirilemez.

İşaret ettiğimiz üzere, taksirli fiil iştirak halinde işlenebilmekle birlikte, TCK'nın suça iştirake ilişkin genel hükümleri taksirli suçlar bakımından uygulanamaz. Keza, birden fazla kişinin katılımıyla işlenen taksirli suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu tutulur (TCK, m. 22, f. 5). Ancak bu hükümler, zamanaşımının kesilmesi bağlamında bize yol göstericilik özelliği taşımaz. TCK, m. 67, f. 2 hükmü, zamanaşımının kesilmesi bağlamında kasıtlı ve taksirli suçlar arasında bir ayırım yapılmasına izin vermemektedir.

Bu mülahazalarla, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun söz konusu kararına katılmamaktayız.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, 5237 sayılı TCK'nın düzenlemelerine rağmen, bu yönde içtihat oluşturulmasının sebebini, hukuk uygulamamızda, beraatle sonuçlanacağı açıkça görülen dosyalarda bile, derdest olan bir davadan, işin esasına yönelik bir değerlendirme zahmetinde bulunmadan bir an evvel kurtulma çabası oluşturmaktadır.

⁴⁹² Mülga 765 sayılı TCK'nın yürürlükte olduğu dönemde, dava zamanaşımını kesen sebeplerin şüpheli ve sanıklardan bir kısmıyla sınırlı olarak etki doğurduğu yönündeki örnek içtihadı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 27.4.1999 tarihli ve 6-82/81 sayılı Kararı oluşturmaktadır: «Sanık Z.K. ile S.A. ve B.Y.nin müşteriler E.K. ile R.Y.nin evlerinde hırsızlık yapmalarından dolayı 17.4.1992 tarihli iddianame ile kamu davası açılmıştır.

Sanık Z.K.'nın şikâyetçi E.Y.'ye yönelik eylem nedeniyle 19.11.1992 tarihinde, sanık S.A.'nın ise 12.3.1993 tarihinde yapılmıştır. Yerel mahkemece ... Z.K.'nın 4.11.1994 tarihinde, diğer sanık S.A.'nın ise 8.11.1993, 25.2.1994 ve 8.1.1997 tarihlerinde yeniden sorguları yapılmış; (yakalanamayan) sanık B.Y.'nin 15.4.1998 tarihinde gıyabi tevkifine karar verilerek, 20.5.1998 tarihli hükümle birlikte hakkındaki dava tefrik edilmiştir.

TCK'nın 104. maddesinde zamanaşımını kesen işlemler; *mahkûmiyet hükmü; yakalama, tevkiif, celp veya ihzar müzekkereleri, sorgu, son soruşturmanın açılması kararı veya iddianame ile dava açılması* olarak belirtilmiş; ikinci fıkrada ise, kesen işlemlerin birden fazla olması halinde sürenin en sonuncusundan itibaren işlemeye başlayacağı, ancak bu nedenlerin zamanaşımını süresini 102. maddede ayrı ayrı belirlenmiş olan müddetlerin yarısının ilavesiyle baliğ olacağı müddetten fazla uzatamayacağı hükmü yer almıştır.

Aynı Yasanın 106. maddesinde ise, bir suçtan dolayı yapılan ve zamanaşımını kesen işlemlerin, o suçlara iştiraki olup da aleyhlerinde takibat veya tahkikat yapılmamış olan kimseler hakkında dahi zamanaşımını keseceği belirtilmiştir.

İnceleme konusu olayda; sanığa yüklenen suç, TCK'nın 491/4. maddesinde düzenlenmiş olup, maddede öngörülen cezanın üst sınırı itibarıyla TCK'nın 102/4. maddesi uyarınca 5 yıllık asli zamanaşımına tabidir. Sanığın inceleme konusu suça ilişkin sorgusu 19.11.1992 tarihinde yapılmıştır. Bu sorgusunda sanığa CMUK'un 135. maddesindeki hakların hatırlatılmamış olması, zamanaşımının kesilmesi açısından sonuca etkili bulunmamaktadır. Zira sorgunun şekline ilişkin bir yasal değişikliğin veya iradesinde olmayan bir yanılmanın sanık aleyhine sonuç doğuracağını kabul etmek olası değildir. Ayrıca TCK'nın 104, 105 ve 106. maddeleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde; 104 ve 105. maddelerdeki düzenlemelerin, haklarında dava açılan kişileri kapsadığı; 106. maddede ise kesici işlemlerin, haklarında takibat ve tahkikat yapılmamış olan kimsele-re de sirayet edeceği öngörülmüş olup; bu düzenleme ile yasalara saygılı olarak duruşmaya gelen kişilerin durumlarını duruşmadan kaçan kişilerin durumlarıyla eşitlemek değil; kaçana imtiyaz tanımamak, onları ödüllendirmemek ve yasa önündeki eşitliği sağlamak amaçlanmıştır.

Bu belirlemeler ışığında sanığın durumu ele alındığında; müsnet suçtan dolayı açılmış bulunan davada sorgusu 19.11.1992 tarihinde yapılmış, araya başkaca kesici bir neden girmediğinden, asli zamanaşımı 19.11.1997 tarihinde gerçekleşmiştir. Sanık, hakkında takibat ve tahkikat yapılmayan konumunda değildir. Bu nedenle, diğer sanıklar hakkındaki zamanaşımını kesen işlemlerin sanığa sirayet etmesi söz konusu» değildir.

Ancak, bir kısım üyeler; "ilk sorgunun usulüne uygun bulunmadığı, zamanaşımı süresinin ikinci sorgudan itibaren hesaplanması gerektiği, zamanaşımının bu tarihe göre gerçekleşmediği" gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmamışlardır.

Keza, Üyelerden S. SELÇUK, şu gerekçeyle çoğunluk görüşüne katılmamıştır:

«Zamanaşımını kesen nedenlerin aynı suça katılan ortakları nasıl etkileyeceği konusunda iki sistem bulunmaktadır. Birincisi, Alman C. Yasasında olduğu gibi, yargılanan sanığı, yani kişiyi gözetken *özel sistem*dir. İkincisi ise, Türk, İtalyan ve Fransız ceza yasalarının öngördüğü *nesnel sistem*dir. Bu ikinci sisteme göre, zamanaşımı kişiler/sanıklar için bir lütuf değil, tersine zamanın geçmesiyle oluşan barışın sarsılmaması düşüncesine dayanan, yani toplum yararını gözetken bir kurumdur. Bu yüzden, zamanaşımını kesen nedenler, adalette eşitlik ve ahlaksallığı, davada birliği sağlamak için yalnızca hakkında kovuşturma yapılan suç ortaklarının değil, hiç kovuşturma yapılmamış, hatta henüz kimliği bile belirlenememiş kişilerin alinyazısını da etkileyeceklerdir. Kaynak İtalyan C. Yasasının gerekçesinin LIII. paragrafında bu husus açıklanmış ve İtalyan Yargıtayı da bu görüşe katılmıştır. Nesnel sistemi benimseyen Türk ve İtalyan ceza yasaları, bu konuda o denli uyarlıdır ki, dengiyi sağlamak için, yakınmadan vazgeçmeyi, kişilerin keyfine bırakmamış, bir sanık için vazgeçmenin, öbür sanıkların alinyazısını da belirleyeceğini ve dolayısıyla etkinin nesnel olacağını vurgulamışlardır (m. 99/2).

Özellikle benimsenen bu nesnel sistemin ışığı altında ortaya çıkan sorunların çözümü şöyle olmak gerekir:

Kesme sebepleri arasında “suçla ilgili olarak **iddianame düzenlenmesi**” gösterilmiştir (m. 67, f. 2, bent c). Dikkat edilmelidir ki, bu durumda dava zamanaşımı **iddianamenin kabul edildiği tarih itibarıyla** kesilmiş olacaktır. Çünkü, iddianamenin salt düzenlenmiş olması, henüz hukuki sonuç doğurmamaktadır. Düzenlenmiş olan iddianamenin kabul edilmesiyle soruşturma evresi sona ermiş ve kovuşturma evresi başlamış olduğuna göre (5271 s. CMK, m. 2, f. 1, bent e ve f), dava zamanaşımı süresinin bu tarih itibarıyla kesildiğini kabul etmek gerekir.

Ancak belirtmek gerekir ki, Yargıtay, dava zamanaşımının, **iddianamenin kabul edilmiş ya da kanuni süre içerisinde iade edilmemiş olması şartıyla düzenlendiği tarih itibarıyla** kesildiğini kabul etmektedir⁴⁹³.

1- Hakkında dava açılan suç ortaklarından her biri için gerçekleşen zamanaşımı, ayrı ayrı kişiler izlenerek, öznel biçimde değerlendirilmeyecek; tersine ortaklardan en son kesmenin söz konusu olduğu failine göre hesaplanacaktır. Adalette eşitlik/ahlakilikle davada birlik ve zamanaşımının toplum yararına olması, nesnel sistemde bu sonucu doğurmaktadır. Esasen TC. Yasasının 106. maddesinin karşıt kavramı da bunu doğrulamaktadır.

2- Hakkında dava açılmamış, hiç yakalanmamış, suçlanmamış, hatta kimliği belirlenememiş suç ortakları için de durum böyledir. TC. Yasasının 106. maddesinde geçen “dahi” sözcüğünün karşıt kavramından ve de bu maddenin “haydisellik/önceliklilik/evleviyet” (a fortiori) kuralıyla yorumundan bu anlam çıkmakta, esasen Türk C. Yasasının nesnel sistemi benimsediği bu madde ile belirlenmektedir. Nitekim İtalyan Yargıtayının kararları da bu doğrultudadır (Örneğin, 7.6.1899, 14.3.1907).

3- Zamanaşımını kesen yargısal işlem de hukuka uygun olmalıdır. Hukuka uygun olmayan bir işlem ne hukuksal sonuç doğurur ne de hak. Örneğin, hukuka uygun “ihzar kararı” zamanaşımını keser ve fakat hukuka aykırı, gereksiz bir ihzar kararı zamanaşımını kesmez. Hukuka aykırılığı açık bulunan bir sorgulama elbette zamanaşımını kesmez. Bu nedenle karar bozulduğunda yeniden yapılan ve hukuka uygun bir sorgulamanın zamanaşımını kesmeyeceğini düşünmek çarpıcı bir yanlış olur ve yanlış işlemlere hukuksal güç kazandırır.

Zamanında yargı önüne çıkan ve yargısal işlemlerle hakkında zamanaşımı işlemeye başlayan, hatta gerçekleşen bir suç failinin; yıllarca yargıdan kaçan bir fail hakkında oluşan zamanaşımını kesme nedenlerinden etkilenmesini adil bulmayan anlayış, öznelci görüştür. Bu öznelci görüş kimilerinin hukuk anlayışlarına uygun gelebilir ve ilk bakışta haklı da görülebilir. Nitekim Alman C. Yasası bu gerekçelerle öznel sistemi benimsemiştir. Ancak, öznelci görüşle çarpışan nesnelci görüşün yukarıdaki gerekçelerini benimseyen yasalar da vardır. Nitekim Türk C. Yasası ve kaynak İtalyan C. Yasası bu sistemi yeğlemiştir; 1930 tarihli İtalyan C. Yasası ise, nesnel sistemin uygulamadaki adil ve yararlı sonuçlarını değerlendirerek, sistemi daha da genişletmiştir. Uygulamacı kendi hukuk anlayışına göre ilk ağızda doğru gördüğü sonucun sağlamasını yapmadan bunu hemen uygulamaya yansıtamaz. İlk, ulaştığı sonucun uyguladığı yasanın sistemiyle bağdaşp bağdaşmadığını incelemek/irdelemek zorundadır. Bu sağlama yapılmadan ulaşılan sonuç uygulamaya yansıtılırsa, yasayla ve sistemle çatışma kaçınılmaz olur. Bu yüzden, öznelci görüşü savunan sayın çoğunluğun ulaştığı sonuç, Türk C. Yasasından soyutlanarak ele alındığında ilk bakışta haklı görülse bile, TC. Yasasının sistemiyle ters düşmektedir.

İtiraf edeyim ki ülkemizde bugüne değin Alman C. Yasasının öngördüğü öznel sistem benimsenerek uygulama yapılagelmiştir. Ayırdında olmayarak bu görüşlere benim de katıldığım olmuştur. Ancak **yanlış bir görüşün yıllardır uygulanması ve kıdem kazanması, onu meşrulaştırmaz ve doğruya dönüştüremez. Olsa olsa yanlış süregen (müzmin) kılar.** Özetle eski görüşlerin yanlışlığı bu denli açık iken onlara hukuksallık kazandırmak olanaksızdır. Yasanın nesnel sistemi gözetilerek eski görüşlerden dönülmelidir.»: CCK., 27.4.1999, 6-82/81.

⁴⁹³ CGK, 16.2.2016, E. 2014/11-315, K. 2016/65.

III. Dava Zamanaşımı ve Muhakeme Şartı Olarak Dava Süresi

Çeşitli kanunlarda, belirli suçlarla bağlantılı olarak soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için muayyen bir sürenin geçmemiş olması şart olarak aranır. Bu durumda bir **muhakeme şartı** olarak **dava süresinden** söz edilir.

Örneğin 9.6.2004 tarihli ve 5187 sayılı “Basın Kanunu”nun 26. maddesinde öngörülen süreler, dava zamanaşımı süreleri değil, muhakeme şartı olarak dava süreleridir. Anılan maddenin ilk fıkrasına göre “*Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının bir **muhakeme şartı** olarak, günlük süreli yayınlar yönünden dört ay, diğer basılmış eserler yönünden altı ay içinde açılması zorunludur.*”⁴⁹⁴,⁴⁹⁵.

Keza, 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 180. maddesinin birinci fıkrasına göre; “*Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.*”

Dava zamanaşımından farklı olarak, bir muhakeme şartı olan dava süresinin durması ve kesilmesi söz konusu olamaz. Ancak, bazı durumlarda kanunda açıkça dava süresinin durabileceği yönünde hükümlere yer verilmektedir. Örneğin basın yoluyla işlenen ve “*kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya karar için gerekli başvurunun yapılmasıyla **dava açma süresi durur. Durma süresi dört ayı geçemez.***” (5187 s. K, m. 26, f. 6). Keza, “*Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan (seçim) suçlar(ın)da izin veya kararın alınması için yapılan müracaat tarihi ile*

⁴⁹⁴ Söz konusu sürelerin başlangıç tarihi, değişik ihtimallere göre belirlenmiştir:

“*Bu süreler **basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten** başlar. Basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin başlama tarihi, **suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihtir.** Ancak bu süreler, Türk Ceza Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen süreleri aşamaz.*” (m. 26, f. 2)

“*Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia edilen eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden süre, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilecek **beraat kararının kesinleşmesinden itibaren** başlar.*” (m. 26, f. 3)

“*Sorumlu müdürün yayımlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi aleyhine açılacak davada süre, **bildirim tarihinden itibaren** başlar.*” (m. 26, f. 4)

“*Kovuşturulması şikâyeteye bağlı suçlarda dava açma süreleri, suç için kanunun öngördüğü dava zamanaşımı süresini aşmamak şartıyla, **suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten** başlar.*” (m. 26, f. 5)

⁴⁹⁵ **İnternet ortamında yapılan yayınlar**, TCK’nın 6. maddesindeki “**basın ve yayın yolu ile**” ibaresi kapsamında değerlendirilse bile, 5187 sayılı Kanun sadece “**basılmış eserler**”in basım ve yayımına ilişkin hükümler içermektedir (m. 1, f. 2). İnternet ortamında yapılan yayınlar “basılmış eser” kavramının kapsamına girmediği için, 5187 sayılı Kanunun 26. maddesi hükümleri internet ortamında yayın yoluyla işlenen suçlar bakımından uygulanamaz. Bu itibarla, internet ortamında yayın yoluyla işlenen suçlar nedeniyle soruşturma başlatılması bakımından genel kurallar geçerlidir.

izin veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre dava süresi hesabına katılmaz. Ancak, bu süre üç ayı geçemez.” 298 s. K, m. 180, f. 2).

Bir **muhakeme şartı** olarak kabul edilen bu süreler zarfında kamu davasının açılmaması halinde, **kovuşturmaya yer olmadığı kararının** verilmesi gerekir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki, kamu davası iddianamenin kabul edildiği anda açılmış sayılır (CMK, m. 175, f. 1). Bu itibarla, muhakeme şartı olan dava süresine riayet edilmeksizin iddianamenin düzenlenmesi halinde, mahkeme **iddianamenin iadesine karar** verecektir. İddianamenin kabulünden sonra durumun anlaşılması halinde ise, CMK’nın 223. maddesinin sekizinci fıkrası hükmü gereğince **düşme kararının** verilmesi gerekir.

IV. Ceza Zamanaşımı

Mahkûmiyet kararının kesinleştiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda mahkûm olunan cezanın infazından sarfinazar edilmesine ise, biz *infaz zamanaşımı* demeyi tercih etmekle birlikte; yeni TCK’nın da “*ceza zamanaşımı*” ibaresini kullanması karşısında (m. 68), biz de bu ifadeyi kullanmaktayız⁴⁹⁶.

Ceza zamanaşımında, kişi belli bir cezaya mahkûm olmuş, bu ceza kesinleşmiş olmasına rağmen; kesinleşme tarihinden itibaren belli bir sürenin geçmiş olması nedeniyle Devlet bu cezanın infazından sarfinazar etmektedir. Ceza zamanaşımının dolması durumunda, mahkûmiyet kararı varlığını muhafaza eder, ancak *infaz edilmez* (m. 68, f. 1)⁴⁹⁷.

Ceza zamanaşımının dolmuş kabul edilebilmesi için “*hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren*” (m. 68, f. 5) geçmesi gereken süreler, hükmolunan **somut cezanın** miktar veya türüne göre farklılık arz etmektedir. Buna göre, ceza zamanaşımı süreleri,

«a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.

b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.

c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.

d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.

e) Beş yıla kadar hapis ve adli para cezalarında on yıl.»dır (m. 68, f. 1).

Belirtmek gerekir ki, “*türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.*” (m. 68, f. 4)

⁴⁹⁶ Kunter, “yerine getirme zamanaşımı” ibaresinin kullanılmasını tercih etmiştir: KUNTER, Ceza Hukukunda Zamanaşımı sh. 6, 127 vd.

⁴⁹⁷ KUNTER, Ceza Hukukunda Zamanaşımı sh. 118 vd.

Ancak, Kanunda çocukların işledikleri suçlarla ilgili olarak ceza zamanaşımı süresinin belirlenmesi bakımından özel bir hükme yer verilmiştir:

“Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.” (m. 68, f. 2).

Dikkat edilmelidir ki, bu süreler, *“kalan ceza miktarı esas alınarak ... hesaplanır.”* (m. 68, f. 5).

Hukuk sistemimizde, bazı suçların belli şartlar altında işlenmesi durumunda ceza zamanaşımının işlemeyeceği kabul edilmiştir. Buna göre, Türk Ceza Kanununun *“İkinci Kitabının Dördüncü Kısımında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.”* (m. 68, f. 3). Keza, soykırım ve insanlığa karşı suçlar ile bu suçları işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma suçlarından dolayı (ceza) zamanaşımının işlemeyeceği kabul edilmiştir (m. 76, f. 4; m. 77, f. 4; m. 78, f. 3)⁴⁹⁸.

Yeni TCK’nın *“Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları”* başlıklı 69. maddesine göre, *“Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam eder.”*

Bu hükmün gerekçesinde şu açıklamalar yer almaktadır⁴⁹⁹:

“Madde metninde cezaya bağlı olan veya mahkemenin verdiği hükümde yer alan hak yoksunluklarının süresinin ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam edeceği belirtilmiştir. Hükmolünmüş olan cezanın infazının gecikmesi, bu cezaya bağlı hak yoksunluklarının uygulanmasını engellemeyecektir. Ancak bu suretle doğan hak yoksunluklarının en fazla ceza zamanaşımı süresi doluncaya kadar devam edeceği maddede hüküm altına alınmıştır.”

Keza, Kanunun *“Müsaderede zamanaşımı”* başlıklı 70. maddesine göre; *“Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez.”*

V. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi veya Durması

Ceza zamanaşımının kesilmesiyle ilgili olarak yeni TCK’nın aynı başlığı taşıyan 71. maddesinde düzenleme yapılmıştır:

⁴⁹⁸ Alman hukukunda “soykırım (genosit) suçu” (Alman CK, § 22a) açısından hem dava zamanaşımı hem de infaz zamanaşımı kabul edilmemiştir. Buna karşılık kasten adam öldürme suçunun nitelikli şekli (“Mord”: Alman CK, § 211) açısından sadece dava zamanaşımı kabul edilmemiştir (Bkz. Alman CK, § 78, f. 2; § 79, f. 2). Keza, hangi suç sebebiyle olursa olsun, mahkûm olunan müebbet hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili olarak infaz zamanaşımı kabul edilmemiştir (Bkz. Alman CK, § 79, f. 2).

⁴⁹⁹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 474.

“Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser.” (f. 1)

“Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir.” (f. 2)

İkinci fıkra hükmüyle ilgili olarak söz konusu madde **gerekçesinde** şu açıklama yer almaktadır⁵⁰⁰:

“Tasarının ilgili maddesinin ikinci fıkrasında zamanaşımını kesen mahkûmiyet bakımından değişiklik yapılmıştır. Tasarıda daha önce işlediği bir suçtan mahkûm olan kimsenin zamanaşımı süresi içinde mahkûm olduğu suç türünden diğer bir suç işlediği takdirde ceza zamanaşımının kesileceği kabul edilmişti. Ancak, madde metninde yapılan değişiklikle, üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlendiğinde zamanaşımının kesileceği kabul edilmiştir.”

Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 23.3.2005 tarihli ve 5320 sayılı Kanunun⁵⁰¹ 15'inci maddesinde **ceza zamanaşımının durmasıyla** ilgili olarak şu hükümlere yer verilmiştir:

“(1) Birden fazla mahkumiyeti olan kişi bu mahkumiyetlerden birine ilişkin cezayı infaz kurumunda çektiği sürece, diğer cezaları açısından ceza zamanaşımı işlemez.

(2) Cezanın infazının ertelenmesi veya durdurulması halinde, bu cezaya ilişkin zamanaşımı işlemez.”

TBMM Adalet Komisyonunun, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin 18.2.2005 tarihli ve Esas 1/536, Karar 67 sayılı Raporunda⁵⁰² bu hususla ilgili olarak şu açıklamada bulunulmuştur:

“Tasarıya, ‘Zamanaşımı’ başlığı altında, birden fazla mahkumiyeti olan kişilerin bu mahkumiyetlerinden birine ilişkin cezanın infaz edildiği süre içinde diğer cezalarının, ceza zamanaşımına uğramayacağına ilişkin yeni 15'inci madde ilave edilmiştir.”

Her ne kadar CMK Yürürlük Kanununa konmuş ise de, söz konusu hüküm, ancak TCK'nın ceza zamanaşımına ilişkin hükümleriyle bağlantılı olarak uygulanma kabiliyetini haizdir.

⁵⁰⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 474.

⁵⁰¹ RG: 31.3.2005/25772 Mükerrer.

⁵⁰² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 803.

Ceza zamanaşımının durması ile ilgili olarak yeni İnfaz Kanununun 118'inci maddesinde de bir hükme yer verilmiştir:

“Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ayırık olmak üzere, askere alınmadan önce ve askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile yedek subaylar hakkında kısa süreli hapis cezaları yerine hükmedilen Türk Ceza Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler ile bu Kanunun 106'ncı maddesinde yazılı adli para cezasının yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır. Bu süreler içinde zamanaşımı işlemez.” (f. 1).

VI. Dava ve Ceza Zamanaşımına İlişkin Ortak Hükümler

Dava ve ceza zamanaşımının ne suretle hesaplanacağı hususunda yeni TCK'nın 72. maddesinde hüküm bulunmaktadır:

“Dava ve ceza zamanaşımı süreleri, gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmî takvime göre hesap edilir.” (f. 1)

Keza, dava ve ceza zamanaşımına ilişkin hükümler re'sen uygulanır. Kişinin bu hükümlerin kendisi hakkında uygulanmasından vazgeçme hakkı bulunmamaktadır:

“Dava ve ceza zamanaşımı re'sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler.” (m. 72, f. 2)

VII. Kabahatlerde Zamanaşımı

5326 s. Kabahatler Kanununun “Soruşturma zamanaşımı” başlıklı 20. maddesine göre;

“Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez.” (f. 1)

“Soruşturma zamanaşımı süresi;

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,

yıldır. Ancak, 89'uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Ka-

nunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer." (f. 2)⁵⁰³

"Nispî idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır." (f. 3)

"Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar." (f. 4)

"Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturmada halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır." (f. 5)

Keza, söz konusu Kanunun "Yerine getirme zamanaşımı" başlıklı 21. maddesine göre;

"Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idari para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez." (f. 1)

"Yerine getirme zamanaşımı süresi;

a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde yedi,

b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde beş,

c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde dört,

d) Onbin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi halinde üç, yıldır." (f. 2)

⁵⁰³ Bu fıkra, 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunla değiştirilmiştir (m. 33).

Değişiklikten önceki fıkra metni şu şekilde idi:

"Soruşturma zamanaşımı süresi;

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,

d) Yirmibin Türk Lirasına kadar idari para cezasını gerektiren kabahatlerde iki,

yıldır."

Bu değişikliğin gerekçesi şu şekildedir:

"Düşük miktardaki idari para cezaları ile ilgili olarak belirlenen soruşturma zamanaşımı sürelerinin uygulamada yetersiz görülmesi dolayısıyla, üst sınır itibarıyla ellibin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde soruşturma zamanaşımını yeniden belirlemiştir." (TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı 5, Sıra Sayısı: 1255, sh. 15).

Fıkranın son cümlesi, bilahare **13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla** metne eklenmiştir (m. 22; Resmi Gazete: 25 Şubat 2011/27857 Mükerrer).

“Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır.” (f. 3)

“Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.” (f. 4)⁵⁰⁴

“Kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.” (f. 5)

VIII. Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Fiiller Dolayısıyla Zamanaşımı

Kanunda, hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili olarak, kanuni tanımlardaki hapis cezası süreleri göz önünde bulundurularak, *dava zamanaşımı süreleri* belirlenmiştir. Buna karşılık, örneğin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda 31.5.2005 tarihli ve 5358 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde⁵⁰⁵, *disiplin hapsine karar verilebilmesi için*, disiplin hapsi süresi göz önünde bulundurularak bir *zamanaşımı süresi* öngörülmüştür. Bunun ifade ettiği anlam şudur: Kişinin belli bir yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, bu yükümlülüğe uygun davranmasını sağlamak amacıyla hakkında disiplin hapsine karar verilmektedir. Bu bakımdan kişinin örneğin belli alacak borç ilişkisinden kaynaklanan ifa yükümlülüğü mevcudiyetini devam ettirdiği sürece bu yükümlülükle ilgili olarak hakkında disiplin hapsine karar verilebilecektir.

Buna karşılık, İcra ve İflas Kanununun 354. maddesinde 5358 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, disiplin hapsi ile ilgili olarak sadece *yerine getirme zamanaşımı süresi* öngörülmüştür⁵⁰⁶.

IX. Şikâyetten Vazgeçme

Yukarıda açıkladığımız şikâyet, mahiyeti itibarıyla bir soruşturma ve kovuşturma koşuludur. Şikâyet hakkına sahip olan mağdur veya suçtan zarar gören, aynı zamanda şikâyetten vazgeçme⁵⁰⁷ hakkına da sahiptir. Nitekim, bu hak, yeni

⁵⁰⁴ Bu fıkra, 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunla değiştirilmiştir (m. 37) (RG: 1 Ağustos 2010/27659). Değişiklikten önce fıkra metni şu şekilde idi:

“Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar.”

6009 s. Kanunla yapılan değişiklikle kabul edilen metin Anayasanın “**Kanun önünde eşitlik**” ilkesine (m. 10) aykırıdır. Aynı kabahati oluşturan fiillerden dolayı verilen yaptırım kararları bakımından yerine getirme zamanaşımı süresinde, bu kararlardan birinin yılın ilk ayının ilk günlerinde, diğerinin ise, yılın son ayının son günlerinde kesinleşmiş olması dolayısıyla bir yıla yakın bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Kötü bir Türkçe ile kaleme alınmış olan Kabahatler Kanunundaki bu değişiklik, Adalet Bakanlığı yetkililerinin açıkladıkları teknik görüşe rağmen, Maliye Bakanlığı yetkililerinin isteği üzerine yapılmıştır.

⁵⁰⁵ RG: 1 Haziran 2005-25832.

⁵⁰⁶ “İcra mahkemesinin ... verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.”

⁵⁰⁷ Aslında “**şikâyetten vazgeçme**” ile “**şikâyetin geri alınması**”, birbirinden farklı kavramlardır. Kişi, bir suçtan dolayı sahip bulunduğu **şikâyet hakkını kullanmaktan vazgeçmiş** olabilir. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda henüz şikâyet vuku bulmuş değildir. Buna karşılık, kişi

TCK'da mağdur veya suçtan zarar görene tanınmış olup, soruşturulması ve kovuşturulması “*şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür*” (m. 73, f. 4). Bu hükmün mefhumu muhalifinden anlaşıldığı gibi, Kanun koyucu bazı suçlar bağlamında şikâyetten vazgeçmeyi kabul etmeyebilecektir.

Şikâyetten vazgeçmenin söz konusu olduğu hallerde, belli bir suçun işlendiğinden bahisle, şikâyet hakkı kullanılmıştır ve fakat, kişi bilahare bu şikâyetini geri almaktadır. Bu nedenle, şikâyetten vazgeçilmesi, başlatılmış olan soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilmesini; kovuşturmanın başlatılması halinde ise, kamu davasının düşmesine hükmedilmesini gerektirmektedir.

Şikâyetten vazgeçme, kural olarak ancak hüküm kesinleşinceye kadar mümkündür. Hüküm kesinleştikten sonra artık şikâyetten vazgeçilemez; daha doğru bir ifadeyle, şikâyetten vazgeçme kabul edilmez. Ancak, Kanun koyucu, bazı suçlar bakımından hüküm kesinleştikten sonra cezanın infazı aşamasında da şikâyetten vazgeçmenin mümkün olabileceğini kabul edebilmektedir. Örneğin, **5941 sayılı Çek Kanunundaki** 6273 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki düzenleme gibi, bilahare **15.7.2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre**, çekin karşılığını ilgili banka hesabında bulundurma yükümlülüğüne rağmen, “*üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi*” hakkında bu nedenle verilen mahkumiyet hükmü (m. 5) kesinleştikten sonra da şikâyetten vazgeçilebilmektedir (m. 6, f. 1, 2). Bu durumda, “*mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, karar verilir.*” (m. 6, f. 1, bent b).

Şikâyetin bölünmezliği kuralının zorunlu bir sonucu olarak; iştirak halinde işlenmiş olan suçlarda, şikâyetten vazgeçme, bütün suç ortakları bakımından aynı sonucu doğurur. Nitekim, yeni TCK'ya göre, “*İştirak hâlinde suç işlemiş sanıklar-dan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.*” (m. 73, f. 5).

Şikâyetten vazgeçme, kural olarak ancak şüpheli veya sanığın kabulü halinde sonuç doğurur. Şikâyetten vazgeçmeye rağmen, şüpheli C. savcısından soruşturmaya, sanık ise mahkemeden kovuşturmaya devam edilmesini talep etme hakkına sahiptir. Nitekim, yeni TCK'ya göre, “*Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.*” (m. 73, f. 6).

Kişinin şikâyetten vazgeçmiş olması, işlenen suç dolayısıyla uğradığı zararların tazminini talep etme hakkını etkilemez. Ancak, şikâyetten vazgeçen mağdur veya suç-

bir suçtan dolayı **şikâyet hakkını kullandıktan sonra**, bu **şikâyetini geri alabilir**. Bu durumda şikâyetin geri alınması söz konusudur. Ancak hukuk uygulamamızda şikâyetten vazgeçme kavramı hep şikâyetin geri alınması bağlamında kullanılmaktadır (Bu hususta bkz. ÖZ-TÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 9. bası, sh. 117).

tan zarar gören, ayrıca, uğradığı zararların tazminini talep etme hakkından da açıkça vazgeçmiş ise, artık bu nedenle hukuk mahkemesinde dava açamaz (m. 73, f. 7).

X. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü

Yeni TCK'nın "*Sanığın veya hükümlünün ölümü*" başlıklı 64. maddesine göre,

"Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsadereyesine hükmolunabilir." (f. 1).

Bu hükmün gereği olarak; soruşturma devam ederken şüphelinin ölümü halinde, C. savcısı ölen şüpheliyle ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verecektir. Kovuşturma devam ederken sanığın ölümü halinde ise, mahkeme ölen sanıkla ilgili olarak kamu davasının düşürülmesine karar verecektir⁵⁰⁸.

Ancak, müsadereye konu eşya ve diğer malvarlığı değerleriyle ilgili olarak davaya devam edilmelidir. Nitekim, madde gerekçesine göre; "*niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve kazanç müsadereyesine ilişkin yargılamaya -sanığın*

⁵⁰⁸ "... kamu davası açılmadan önce şüphelinin ölmesi halinde kovuşturma imkanının bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı, kamu davası açıldıktan sonra sanığın ölmesi halinde ise mahkemeye düşme kararı verilecektir. Ölümün ceza ilişkisini sadece ölen kişi bakımından sona erdirdiğinden iştirak halinde işlenen suçlarda diğer sanıklar hakkında davaya devam edilecek, sanığın ölümü niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak müsadere kararı verilmesine engel olmayacaktır. Sanığın ölümü ceza ve infaz ilişkisini düşürürken, hakkındaki mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olan hükümlünün ölümü sadece hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarının infaz ilişkisini ortadan kaldıracaktır. Buna bağlı olarak ölümden önce tahsil edilmiş bulunan para cezaları mirasçılara iade edilmeyecek, buna karşın tahsil edilmemiş bulunan para cezaları da mirasçılardan istenmeyecek, bunun yanında müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin hükümler ölümden önce kesinleşmiş olmak kaydıyla infaz olunacaktır.

Görüldüğü gibi, suç teşkil eden bir fiilin işlenmesiyle fail ile devlet arasında doğan ceza ilişkisi, bu fiili işleyen sanığın ya da hükümlünün ölümüyle cezaların şahsiliği ilkesi nedeniyle başkası sorumlu tutulamayacağından, düşmektedir. Ölüm, bir vakıa olan suçu ortadan kaldırmayacak, suçtan sorumlu tutulacak kişi olmadığından, devletin suçla birlikte ortaya çıkan cezalandırma sorumluluk ve yetkisini sona erdirecektir.

Temyiz aşamasında sanığın öldüğüne ilişkin bir iddianın ortaya çıkması ya da UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) vasıtasıyla alınan nüfus kaydında öldüğü bilgisinin yer alması veya sanık adına tebliğnamenin tebliğ edilmesi için çıkarılan evrakın öldüğünden bahisle iade edilmesi gibi durumlarda, ölümün kamu davasının düşürülmesini gerektiren bir neden olduğu da göz önüne alınarak, ölüm nedeniyle düşme kararının temyiz merciince dosya üzerinde yapılan inceleme sırasında verilmesi yerine, ölüm bilgisi nedeniyle diğer yönleri incelenmeyen hükmün bozulmasına karar verilerek yerel mahkemelerce mahallinde yapılan araştırmada sanığın öldüğünün kesin olarak belirlenmesinden sonra düşme kararı verilmesinin sağlanması gerekmektedir." CGK, **5.3.2013**, E. 2013/8-131, K. 75. Ayrıca bkz. CGK'nın **5.3.2013**, tarihli ve K. 76 ilâ 80 sayılı; **30.4.2013** tarihli ve K. 155 ilâ 200 sayılı Kararları; CGK, **23.6.2015**, E. 2014/3-514, K. 2015/246; CGK, **23.6.2015**, E. 2014/1-692, K. 2015/247; CGK, **24.11.2015**, E. 2015/4-316, K. 2015/413; CGK, **20.9.2016**, E. 2014/6-702, K. 2016/313; CGK, **11.10.2016**, E. 2014/14-631, K. 2016/349.

ölümüne rağmen devam edilmesinin mümkün olduğu hâllerde- devam edilip hasıl olan neticeye göre bir karar verilecektir.”⁵⁰⁹.

Müsadereye tabi eşya ve diğer malvarlığı değerleriyle ilgili olarak izlenecek yargılama usulü, CMK’nın 256 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.

Keza, “Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur.” (m. 64, f. 2). Madde gerekçesine göre; “Hükümlünün ölümü henüz infaz edilmemiş hapis ve adli para cezasını ortadan kaldırır. Ancak adli para cezası kısmen veya tamamen infaz edilmiş ise artık devletten geri istenemez. Buna karşılık hükümlünün sağlığında verilmiş olup kesinleşen müsadere ve yargılama giderleri hükümlünün mirasçılarından istenebilir.”⁵¹⁰:

XI. Af

Af, Anayasa’ya göre “genel af” ve “özel af” olarak ikiye ayrılmaktadır (m. 87; m. 104, f. 2, bent b, alt bent 13). Genel ve özel affın hukuki sonuçlarıyla ilgili düzenleme, yeni TCK’nın “Af” başlıklı 65. maddesinde yapılmıştır:

“Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.” (f. 1)

“Özel af ile, hapis cezasının infaz kurumunda çektilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektililecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir.” (f. 2)

“Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.” (f. 3)

Madde gerekçesinde özel afla ilgili olarak şu açıklamaya yer verilmiştir^{511, 512}:

⁵⁰⁹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 470 vd.

⁵¹⁰ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 470 vd.

⁵¹¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 472.

⁵¹² Aşağıdaki karar, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından özel af yetkisinin kullanılmasına ilişkin bir örnek olarak gösterilmiştir (RG: 20 Ağustos 2008/26973):

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2008/49

Özel evrakta sahtecilik suçundan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 7/6/2006 tarihli ve E: 2006/126, K: 2006/212 sayılı ek kararıyla 2 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hapis cezasının konutunda çektililmesine karar verilerek cezası kesinleşen, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hasan Halife Mahallesi, Cilt No: 24, Hane No: 937, Birey Sıra No: 6’da nüfusa kayıtlı, Mehmet Sabri ve Kamer’den olma 29/10/1926 doğumlu, 42013485108 T.C. Kimlik Numaralı Necmettin ERBAKAN’ın kalan **cezası**, Adalet Bakanlığının 15/8/2008 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-125-2948-2008/9761/44252 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçen **sürekli hastalık durumunda** bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 26/5/2008 tarihli ve B.03.1.ATK.0.06.00.08/33284-4241-3789 sayılı raporu

“Maddenin ikinci fıkrasında özel affın mahiyeti açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Buna göre özel af ile sadece hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebileceği, infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılabileceği veya para cezasına çevrilebileceği kabul edilmiştir. Bu sistemde özel af sadece hapis cezaları açısından kabul edilebilecektir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, özel affın cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları hakkında herhangi bir etkisinin olmadığı, açık bir şekilde vurgulanmıştır.”⁵¹³

sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca **kaldırılmıştır**. 19 Ağustos 2008

Abdullah GÜL, CUMHURBAŞKANI.

⁵¹³ İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargo ve ablukayı delmek amacıyla yönelik girişim çerçevesinde, 2010 yılının mayıs ayının sonlarına doğru, Gazze’ye gitmek üzere Türkiye’den bir yolcu gemisi ile insani yardım malzemesi taşıdığı belirtilen çok sayıda yük gemisi yola çıkarılır. Yolcu gemisinde bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çok sayıda insan bulunur. İsrail, gemilerin kendi karasularına girmesini engellemek için girişimde bulunur. Bu çerçevede, gemiler henüz kendi karasuları dışında iken. İsrail güvenlik kuvvetleri olaya silahlı müdahalede bulunur. Bu silahlı müdahalede, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çok sayıda insan **öldürülür** ve **yaralanır**.

Bu olay üzerine Türkiye’de İsrail güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma sonucunda, haklarında soruşturma yapılan kişilerin Türkiye’de bulunmamasına rağmen, iddianame düzenlenmiş ve bu davanın görülmesine bu kişilerin gıyabında İstanbul’da başlanmıştır (İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, E. 2012/264).

Bu dava devam ederken 28.06.2016 tarihinde, **“Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması”** imzalanmıştır. Bu Anlaşmanın onaylanması TBMM tarafından 20.8.2016 tarihli ve 6743 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Söz konusu Anlaşma, 7.9.2016 tarihli ve 2016/9145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır (Anlaşma metni için bkz. RG. 9 Eylül 2016 / 29826).

Anlaşmanın konusu, esas itibarıyla “tazminat” ödenmesine ilişkin ise de; 4. maddesinde, tarafların ve “taraflar adına hareket edenlerin” söz konusu olayla ilgili olarak **sorumluluktan muaf** tutulmalarını sağlamaya yönelik hükme yer verilmiştir. Bu hükme göre, söz konusu olay bağlamında “taraflar adına hareket edenlere”, “hukuki veya başka bir sorumluluk” yüklenemeyecektir. Yani bu kişiler, söz konusu hükümle **ceza hukuku bakımından sorumsuz** kılınmıştır.

Kanunla onaylanması uygun bulunan, onaylanan ve usulüne göre yürürlüğe konulan bu anlaşma hükmü, gerçekleşmiş bir olaya ilişkin olarak hukuki ve cezai sorumluluktan muafiyet getirdiği için, bir **genel af** mahiyeti taşımaktadır. Bu itibarla, söz konusu Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin 20.8.2016 tarihli ve 6743 sayılı Kanun bağlamında Anayasa’nın af kanununa ilişkin TBMM Genel Kurul oylamasında aradığı çoğunluk şartı (Any. m. 87) bakımından sorunlu olsa bile, bir **af kanunu** mahiyeti taşımaktadır.

Dikkat edilmelidir ki, bu hükümde yer alan “taraflar adına hareket edenler” ibaresi, **münhasıran İsrail güvenlik görevlilerini** kapsamaktadır. Zira bu olay bağlamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına resmen hareket eden herhangi bir kişinin varlığı, tartışma konusu yapılmamaktadır.

Keza belirtelim ki, **bu sorumsuzluk hükmü, söz konusu sivil girişimi başlatan, İsrail karasularına girmeye çalışan, İsrail güvenlik görevlilerine karşı herhangi bir şekilde direniş gösteren kişileri kapsamamaktadır**. Başka bir ifadeyle, **bu kişiler, İsrail Devleti tarafından halen söz konusu girişim bağlamında ceza hukuku bakımından sorumlu tutulabilecek durumdadırlar!**

XII. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi

Davanın ve cezanın düşmesinin etkisi, yeni TCK'nın aynı başlığı taşıyan 74. maddesinde düzenlenmiştir:

“Genel af, özel af ve şikâyetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez.” (f. 1)

“Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan şahsi hak davasını etkilemez.” (f. 2)

“Cezanın düşmesi, şahsi haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri etkilemez. Ancak, genel af hâlinde yargılama giderleri de istenemez.” (f. 3)

Kısaca belirtmek gerekir ki, bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası itibarı bakımından düştüğü acı durumun bir göstergesidir.

Dördüncü Bölüm MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU

§28. Ceza Hukukuna İlişkin Türk Kanunlarının Uygulama Alanı

I. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından Kural

Türkiye’de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, faileri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, Ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır¹. Zira, TCK’ya göre, “*Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır.*” (m. 8, f. 1, birinci cümle).

Bir suçun Türkiye’de işlenmiş sayılması için ölçüt yine TCK’da belirlenmiştir:

“Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi hâlinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.” (m. 8, f. 1, ikinci cümle)².

Dikkat edilmelidir ki, bu hükümde yer alan “fiil” ibaresinden, suçun kanuni tanımında yer alan hareketleri, yani suçun icra hareketlerini anlamak gerekir. Örneğin dolandırıcılık suçunun icra hareketlerinden birini oluşturan hile, Türkiye’de gerçekleştirilir; buna karşılık, haksız menfaat, yurt dışında bulunan bir banka hesabından diğer bir hesaba para aktarma suretiyle temin edilir. 8. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesine göre, dolandırıcılık suçunun icra hareketlerinden sadece hile Türkiye’de gerçekleştirilmiş olsa bile, suç Türkiye’de işlenmiş sayılacaktır. Yine, bir suçun işlenmesine Türkiye’de başlanmış olmakla beraber, icrasına başka bir ülkede devam edilmiş veya suç bu ülkede tamamlanmış olabilir ya da; yabancı bir ülkede işlenmesine başlanan suçun icrasına

¹ Ceza kanununun yer bakımından uygulama alanına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “*Non bis in idem Kuralının Milletlerarası Değeri ve TCK’nın 10/A Maddesi Hükümüne İlişkin Değerlendirme*”, in: Yargıtay Dergisi, cilt 28, Temmuz 2002, sayı 3, sh. 323 vd.; aynı yazar: *TCK’nın 5. Maddesine İlişkin Yargıtay’ın İki Farklı Kararının İncelenmesi, Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Etkisi*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LI, yıl 1985, sayı 1-4, sh. 627 vd.

² Ancak, belirtmek gerekir ki; Yargıtay, 765 s. (mülga) TCK’ya ilişkin uygulamada suçun işlendiği yerin belirlenmesi açısından “*yakın ve aralıksız netice*”nin dikkate alınması gerektiği görüşündedir. Bu itibarla, Yargıtay, Bulgaristan üzerinde uçakta silahla yaralanmış olan kimse- nin bilahare İstanbul’da ölmesi olayında, suçun Türkiye’de değil, Bulgaristan’da işlendiği yönünde karar vermiştir: CGK, 31.10.1949, 1-108/93 (Gözübüyük, A. Pulat: *Türk Ceza Kanunu Şerhi*, 5. bası, İstanbul, sh. 104). Ayrıca bkz. DÖNMEZER, Sulhi: *Yabancı Memlekette İşlenen Suçlar, Siyasî Suçlar ve Nisbi Siyasî Suçlar*, in: İstanbul ÜHFM, cilt XV, yıl 1949, sh.760 vd.; DÖNMEZER/ERMAN I, no. 386; ÖNDER, Genel Hükümler I, sh. 194; CEN- TEL, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh. 76.

Türkiye’de devam edilmiş olabilir. Keza, bir suçun seçimlik hareketlerinden biri yabancı ülkede gerçekleştirilmiş olmakla beraber, diğer bir seçimlik hareket Türkiye’de gerçekleştirilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda suçun Türkiye’de işlendiğini kabul ederek uygulama yapmak gerekir³.

Buna karşılık, icra hareketleri yurt dışında gerçekleştirilen bir suçun işlenişine Türkiye’de bulunan bir kişinin azmettiren veya yardım eden sıfatıyla iştirak etmiş olması halinde, suçun Türkiye’de işlendiğini kabul etmek imkanı bulunmamaktadır⁴. Örneğin, A’nın Almanya’da işlediği kasten öldürme suçunun işlenişine Türkiye’de bulunan B, azmettiren veya yardım eden sıfatıyla iştirak etmiş olsun. Bu örnekte suçun icra hareketleri yurt dışında gerçekleştirildiği için, suç yurt dışında işlenmiş sayılmalıdır. Almanya’da işlenen kasten öldürme suçundan dolayı B’nin azmettiren veya yardım eden sıfatıyla cezalandırılabilmesi için, TCK’nın 18. maddesi ve ilgili iade anlaşması (Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi) hükümlerine istinaden suçun işlendiği ülkeye geriverilmesi gerekir. B’nin suçun işlendiği ülkeye iadesinin mümkün olmaması halinde, TCK’nın 11 ve 13. maddeleri hükümlerine göre Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılanıp cezalandırılması yoluna gidilebilir.

İcra hareketleri Türkiye’de gerçekleştirilen bir suçun işlenişine yurt dışında bulunan bir kişi azmettiren veya yardım eden sıfatıyla iştirak etmiş olabilir. Bu durumda, suçun kanuni tarifinde belirtilen fiil Türkiye’de işlendiği için, bu suç dolayısıyla fail ve diğer suç ortakları hakkında Türkiye’de yargılama yapılacak ve Türk kanunlarına göre cezaya hükmolunacaktır. Bu suçun işlenişine yurt dışında bulunan bir kişi azmettiren veya yardım eden sıfatıyla iştirak etmiş olsa bile, suçu oluşturan fiil Türkiye’de işlendiği için bu kişi hakkında da Türkiye’de yargılama yapılacak ve Türk kanunlarına göre cezaya hükmolunacaktır. Ancak, bunun için, kişinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir. Örneğin, A’nın Türkiye’de işlediği kasten öldürme suçunun işlenişine Almanya’da bulunan B, azmettiren veya yardım eden sıfatıyla iştirak etmiş olsun. Bu örnekte suçun icra hareketleri Türkiye’de gerçekleştirildiği için, suç Türkiye’de işlenmiş sayılmalıdır. Bu suçtan dolayı B’nin azmettiren veya yardım eden sıfatıyla cezalandırılabilmesi için, TCK’nın 18. maddesi ve ilgili iade anlaşması (Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi) hükümlerine istinaden Türkiye’ye iadesinin sağlanması gerekir⁵.

³ Yayın yoluyla işlenen suçlarda, yayının yapıldığı her yerde suçun işlendiğini kabul etmek gerekir. Bu durum, internet ortamında yapılan yayın yoluyla işlenen suçlar bakımından da söz konusudur. Başka bir deyişle, internet ortamında yapılan yayın yoluyla işlenen suçlarda internet ortamındaki içeriğe ulaşılabilen her yerde suçun işlendiğini kabul etmek gerekir. Ancak, belirtelim ki, Ceza Muhakemesi Kanununda bu suçlardan dolayı yer bakımından yetkili mahkemenin belirlenmesi ile ilgili olarak sınırlayıcı hükümler yer almaktadır (m. 12).

⁴ Bkz. TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, Uluslararası Ceza Hukuku, s.90.

⁵ Bu itibarla, *Artuk*’un söz konusu maddede iştirak halinde işlenen suçlarla ilgili olarak suçun işlendiği yerin ne suretle tespit edileceği hususunda hüküm bulunmamasının bir eksiklik oluş-

TCK'nın söz konusu maddesinde, ayrıca, suçun hangi hallerde Türkiye'de işlenmiş sayılacağına dair hüküm bulunmaktadır:

“Suç;

- a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında,
- b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla,
- c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla,
- d) Türkiye'nin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı,

turduğu yönündeki eleştirisinin (ARTUK, Mehmet Emin/ÇINAR, Ali Rıza: *Yeni Bir Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Alt Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2004, sh. 74) teorik bir dayanağı bulunmamaktadır. *Artuk*, bu eleştirisini Alman Ceza Kanununun 9. maddesinde yer alan düzenlemelere dayandırmaktadır. Söz konusu maddenin *Artuk* tarafından yapılan tercümesine göre;

"(1) Fiil, failin harekette bulunduğu veya ihmal halinde harekette bulunması gerektiği veya kanuni tipe ait neticenin gerçekleştiği veya failin tasavvuru gereğince, gerçekleşmesi gerektiği her yerde işlenmiştir.

(2) İştirak halinde işlenen suçlarda, gerek fiilin işlendiği yerde, gerekse şerikin harekette bulunduğu veya ihmal halinde harekette bulunması gerektiği veya kendi tasavvuruna göre fiilin işlenmesi gerektiği her yerde meydana gelmiştir. Şerik yurt dışında işlenen bir suçta, ülke içinde yaptığı bir hareket ile iştirak etmişse, işlendiği yer hukukuna göre fiil suç teşkil etmese dahi, iştirak hakkında Alman Ceza Kanunu uygulanır."

Ancak, belirtmek gerekir ki, *Artuk*'un Alman Ceza Kanununun bu hükmünü esas alarak yaptığı şu açıklamalar, bizim açıklamalarımızla örtüşmektedir:

"... iştirak halinde işlenen suçun icra hareketleri ya da neticesi Türkiye'de gerçekleşmişse, suç Türkiye'de işlenmiştir ve tüm şerikler hakkında TCK. uygulanır. Bu ihtimalde, icra hareketlerini gerçekleştirilmeyen yardım eden ile azmettirenin Türkiye'de bulunmaması önem arz etmez. Buna karşılık failin eylemi yabancı ülkede işlemesi halinde, Türkiye'de bulunan yardım eden veya azmettiren, yurt dışında işlenmiş bir suçta iştirak etmiş olmaktadır. Bu ihtimalde Türkiye'de bulunan azmettiren ile yardım edenin Türkiye'de yargılanması ve cezalandırılması, yurt dışında işlenen suçlar bakımından kabul edilen esaslar çerçevesinde olanaklıdır (TCK. m.10-13). Doğal olarak bu ihtimalde, failin yurt dışında işlediği fiilin, kasti bir eylem olması ve o ülke yasalarına göre cezalandırılabilir nitelikte bulunması gerekir. Fail, şahsi bir cezasızlık nedeninden ötürü cezalandırılmıyorsa, bu husus Türkiye'deki yardım edenin veya azmettirenin cezalandırılmasına engel olmaz (TCK. m.40/1)." (ARTUK/ GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, Dördüncü Bölüm, §1, I, 3, B, d).

Buna rağmen *Artuk*, yeni TCK'da Alman Ceza Kanunundakine benzer bir hükmün olmamasının cezalandırmada bir boşluk yaratacağı yönünde görüş ileri sürmektedir. *Artuk*'un bu endişesi, klasik anlayıştan kaynaklanmaktadır. Örneğin C'yi Cenevre'de öldüren B'yi bu fiili işlemeye Lyon'dan yazdığı mektupla A azmettirir. Bu durumda klasik anlayışa göre "(A) yönünden suç hem Fransa hem de İsviçre'de işlenmiş sayılacaktır." (ARTUK/GÖKCEN/ YENİDÜNYA, Genel Hükümler, Dördüncü Bölüm, §1, I, 3, B, d). Bu gibi durumlarda, klasik anlayış benimsendiği takdirde, azmettiren veya yardım edenin suçun işlendiği yer dışında başka bir devlette yargılanması yoluna gidilecektir ve hiçbir zaman suçun işlendiği ülke devletine iadesi yoluna gidilemeyecektir. Bu yöntemin sağlıklı sonuç vermeyeceği kanısındayız.

İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılır.” (m. 8, f. 2)⁶.

Bu hususla ilgili olarak madde **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir⁷:

“Türk kanunlarının uygulanması bakımından Türk Ülkesinin anlamı açıklanmış ve Türk kara ve hava sahaları ile karasularında işlenen suçların Türkiye’de işlenmiş sayılacakları belirtilmiştir. Karasularının anlamı buna ilişkin Kanuna göre belirlenecektir.

Bundan başka açık denizlerde ve bu denizlerin üzerindeki hava sahasında her çeşit Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla işlenen suçlarla, askerî deniz ve hava araçlarına özgü olmak kaydıyla, yabancı karasularında veya hava sahalarında işlenen suçların Türkiye’de işlenmiş sayılacakları maddede belirtilmiştir.

1 ilâ 10 Mart 1988 tarihlerinde Roma’da toplanan “Denizde Seyrüsefer Güvenliğine Karşı İşlenen Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi Hususundaki Konferans” sonunda Ülkemizin “Deniz Seyrüsefer Güvenliğine Karşı İşlenen Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi” ve “Kıta Sahanlığındaki Sabit Platformların Güvenliğine Karşı İşlenen Kanuna Aykırı Eylemlerin Önlenmesi”ne ilişkin protokolü imzalamış bulunması nedeniyle Türkiye’nin kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı işlenen suçların da Türk ülkesinde işlenmiş suç sayılacağına dair olan (d) bendi kaleme alınmıştır.”

Türkiye’de işlenmiş olan suç dolayısıyla yabancı devlet mahkemelerince hüküm verilmiş olsa bile, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanmak üzere Türkiye’de yeniden yargılama yapılacaktır. Zira yeni TCK’ya göre;

“Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır.” (m. 9).

Dolayısıyla, bu durumda *non bis in idem* kuralı geçerli değildir⁸. Bilindiği gibi, *non bis in idem* kuralı, somut bir vakıayla ilgili olarak belli bir kişi hakkında

⁶ *Özbek*, yabancı bir devletin liman veya karasularında bulunan Türk gemisinde işlenen suçun dahi Türkiye’de işlenmiş sayılacağına kabulünün, geminin karasularında veya limanında bulunduğu devlet ile Türkiye arasında yer bakımından yetki ile ilgili olarak sorunlara neden olabileceğini düşünmektedir (ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 3. bası, sh. 218 vd.). Türk bayrağını taşıyan ve yabancı bir devletin liman veya karasularında bulunan gemide işlenen suçun aynı zamanda bu devletin ülkesinde işlenmiş olduğunun kabulü doğrudur. Ancak, bu durumda, *non bis in idem* kuralına geçerlilik tanımayan TCK’nın sistemine göre (m. 9), geminin bulunduğu devlet mahkemelerinde bu suçtan dolayı hüküm verilmiş olsa bile, Türkiye’de yeniden yargılama yapılabilecektir. Ancak, 16. maddede düzenlenen mahsup hükmü bu durumda bir sorun çıkmasının önüne geçecektir.

⁷ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 410 vd.

⁸ *Artuk*, *non bis in idem* kuralının milletlerarası ceza hukukunda da istisnasız olarak uygulanması gerektiği düşüncesindedir. Bu nedenle, söz konusu 9. madde hükmünü eleştirmektedir

soruşturma veya kovuşturma yapılmakta ise, aynı şahıs hakkında aynı fiilden dolayı ayrıca soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağını ifade etmektedir. Keza, bu kural gereğince;

*“Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir **hüküm** veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.”* (CMK, m. 223, f. 7)^{9,10}.

Bu fıkra metninde yer alan “hüküm” tabiri, kesinleşmiş olan sonkararı ifade etmektedir¹¹. Bu itibarla, kesinleşmiş beraat veya mahkûmiyet kararlarının non bis in idem etkisi doğuracağı hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu gerçek Yargıtay kararlarında da ifadesini bulmuştur:

*«Sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılmış, **beraat** kararı verilerek kesinleşmiş olduğu göz önüne alınmadan, bu kez yiyicilik (irtikâp) iddiasıyla açılan dava üzerine duruşma yapılarak mahkûmiyet kararı verilmesi doğru değildir.»*¹².

Ancak, davanın düşmesi veya durması kararları açısından sorun ortaya çıkmaktadır. CMK’nın 223. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine göre,

“Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür.”

1412 s. (mülga) CMUK’un (m. 253, f. 2) aksine, durma kararı 5271 s. CMK’da hüküm olarak kabul edilmemiştir. Bu nedenle, durma kararı non bis in idem etkisi doğurmaz. Durma kararı, muhakemenin bir engelle karşılaşmasında ortaya çıkar. Bu engel ortadan kalktığı anda, muhakemeye kaldığı yerden devam edilir. Bu niteliği itibarıyla, durma kararı, non bis in idem etkisi doğurmaz. Başka bir deyişle, durma kararı, işin esası hakkında yani sanığın suçu işleyip işlemediği hususunda bir kanaat ifade etmez.

Davanın düşmesi veya reddi kararları da, işin esası hakkında yani sanığın suçu işleyip işlemediği hususunda bir kanaat ifade etmeyen, uyumsuzluğun esası hak-

(ARTUK/ÇINAR, Türk Ceza Kanunu Reformu, sh. 75; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, Dördüncü Bölüm, §1, I, 4. Ayrıca bkz. YARSUVAT/BAYRAKTAR ve diğerleri, sh. 292). Halbuki, aşağıda da açıklanacağı üzere, milletlerarası ceza hukuku uygulamasında non bis in idem kuralına ancak anlaşmalarda veya kanunlarda açık hüküm bulunan hallerde geçerlilik tanınmaktadır.

⁹ Evrensel hukukun temel ilkelerinden biri olan *non bis in idem* kuralı, ilk defa 1973 yılında yapılan değişiklikle (1696 sayılı Kanun) 1412 s. (mülga) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ifade edilmişti:

*«Aynı konuda, aynı sanık için evvelce verilmiş bir **hüküm** veya açılmış bir dava var ise davanın reddine karar verilir.»* (m. 253, f. 3).

¹⁰ Bkz. CGK, **13.4.2010**, E. 2010/1-9, K. 2010/83.

¹¹ KUNTER, Nurullah: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 10. bası, İstanbul, 1998, no: 65; YURTCAN, Erdener: *CMUK Şerhi*, 3. bası, İstanbul, Mart 2000, sh. 558 vd.

¹² 5. CD, 21.12.1983, 3236/4400 (YKD, Şubat 1984, sh. 310).

kında karar verilmesini engelleyen bir durumun varlığı dolayısıyla verilen kararlardır. Bu nedenle, düşme veya davanın reddi yönündeki kararların, “gerçek anlamda son karar” olmadığından söz edilmektedir¹³. Başka bir deyişle, düşme kararlarının ya da ceza davasının reddi yönünde verilen kararların, non bis in idem etkisinden söz edilmemesi gerekir¹⁴.

Nitekim, “İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek 7 No’lu Protokol”ün 4. maddesinin 1. fıkrası, bu düşünceden hareketle ifade edilmiştir. Buna göre;

«Hiç kimse bir devletin ceza usulüne ve hukukuna uygun olarak **mahkûm** edildiği ya da **beraat** ettiği bir suçtan dolayı aynı devletin kazaî yetkisi altındaki yargılama usulleri çerçevesinde yeniden yargılanamaz veya mahkûm edilemez.»¹⁵

Bu itibarla, milletlerarası ceza hukuku uygulamasında ancak işin esası hakkında verilmiş olan kararlara non bis in idem etkisini tanımak gerekir. Durum böyle olunca, CMK’nın 223. maddesinin birinci fıkrasında hüküm olarak kabul edilen son kararlardan sadece **beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet ve güvenlik tedbirine hükmedilmesi** hallerinde, non bis in idem etkisine sahip hükümden söz edilebilmelidir.

765 s. (mülga) TCK’nın sisteminde, Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimsenin, Türkiye’de yeniden yargılanabilmesi bakımından, Türk vatandaşı veya yabancı oluşuna göre ayırım yapılmıştır.

a) Fail, Türk vatandaşı ise, Türkiye’de TCK hükümleri esas alınmak suretiyle *re’sen* yeniden yargılanacaktır. Bu yeniden yargılama için herhangi bir izin veya talebe gerek bulunmamaktadır.

b) Fail, yabancı ise, “Adalet Bakanının talebi üzerine” Türkiye’de TCK hükümleri esas alınmak suretiyle yeniden yargılanacaktır.

Vatandaşa nazaran yabancı lehine olan bu ayırım, yeni TCK’nın sisteminde “Anayasa’da güvence altına alınan eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı düşüncesiyle, ... ortadan kaldırılmıştır.”¹⁶

Yabancı ülkede mahkûm olunan ve infaz edilen cezanın Türk kanunları esas alınmak suretiyle Türkiye’de yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilip edilmeyeceği konusunda mülga 765 s. Kanunda bir hüküm

¹³ YURTCAN, CMUK Şerhi, sh. 560.

¹⁴ Aksi fikir için bkz. TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, Uluslararası Ceza Hukuku, sh.94.

¹⁵ Tarih sürecinde non bis in idem kuralı kapsamında sadece beraat ve mahkûmiyet kararlarının göz önünde bulundurulduğu vakıası hakkında bilgi için ayrıca bkz. YURTCAN, Erdener: *Ceza Yargılamasında Kesin Hüküm*, 2. bası, İstanbul, 1987, sh. 10 vd.

¹⁶ TCK, m. 9 gerekçesi: TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 412.

bulunmamaktaydı. Bu boşluğu doldurmak amacıyla yeni TCK'nın 16. maddesinde mahsup hükmüne yer verilmiştir:

“Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilir.”

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir suçun işlenmesine Türkiye’de başlanmış olmakla beraber, icrasına başka bir ülkede devam edilmiş veya suç bu ülkede tamamlanmış olabilir ya da; yabancı bir ülkede işlenmesine başlanan suçun icrasına Türkiye’de devam edilmiş olabilir. Keza, bir suçun seçimlik hareketlerinden biri yabancı ülkede gerçekleştirilmiş olmakla beraber, diğer bir seçimlik hareket Türkiye’de gerçekleştirilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda suçun Türkiye’de işlendiğini kabul ederek uygulama yapmak gerekir.

Aynı şekilde, meselâ uyuşturucu maddenin Türkiye’den ihracı fiili, ihracatın gerçekleştiği ülke açısından ithalat olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, aynı fiil, Türkiye açısından uyuşturucu maddenin ihracı suçunu oluştururken; ithalatın gerçekleştiği ülkede ise, uyuşturucu madde ithalatı suçunu oluşturmaktadır. Bu durumda da suçun Türkiye’de işlendiğini kabul ederek uygulama yapmak gerekir. Ancak, yabancı ülkede bu ülkeye (Türkiye’den) uyuşturucu madde ithalinin gerçekleştirilmesi dolayısıyla failer bir cezaya mahkûm edilmiş ve hatta, bu ceza infaz da edilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda, yurt dışında mahkûm olunan ve infaz edilen ceza, aynı fiil dolayısıyla Türkiye’de yapılan yargılama sonucunda mahkûm olunan cezadan mahsup edilmelidir. Nitekim, bu gereklilik dolayısıyla, 765 s. (mülga) TCK'nın 403. maddesinde 1991 yılında 3756 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte, Kanuna bu yönde hüküm konulmuştur:

«Böylece ihraç edilmiş maddeler dolayısıyla yabancı memlekette hükmedilmiş ve çekilmiş veya yabancı ülkede çekilmemiş olmakla beraber Türkiye’de infazı kabil cezalar çekildikleri takdirde, ihraç sebebiyle hükmedilecek cezadan indirilir.» (m. 403, f. 4)¹⁷.

¹⁷ Bu hususla ilgili olarak şu örnek olay açıklayıcıdır (Örnek olay hakkında bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku(3), sh. 476, 480, 500, 504/505):

Y, Beyrut’tan aldığı uyuşturucu maddeyi kamyonunda yaptığı özel bölmelere yerleştirerek ülkeye sokmuştur. Bu uyuşturucu madde, Yunanistan’a sokulurken Yunan gümrük yetkililerince yapılan aramada ortaya çıkarılmıştır. Y, Yunanistan’da yapılan yargılama sonucunda 3 yıl hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmuş ve cezası infaz edildikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edilmiştir.

Y, yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi önce yurda ithal etmiştir. Bu maddeyi tekrar yurt dışına ihraç etmiştir. TCK sisteminde uyuşturucu maddenin *imal veya ithali* (seçimlik hareketli) bağımsız bir suç oluşturmaktadır (m. 403, f. 1). Uyuşturucu maddenin *ihracı* ise ayrı bir suç oluşturmaktadır (m. 403, f. 1). Dolayısıyla, Y her iki suçtan ayrı ayrı sorumlu tutulacaktır (m. 403, f. 3). Ancak, uyuşturucu maddenin ihracı (Yunanistan’a ithali) dolayısıyla Y, Yunanistan’da mahkûm olmuş ve cezası da infaz edilmiştir.

Y, Türkiye’den uyuşturucu madde ihracı suçunu işlemiştir. Her ne kadar *aynı fiil* nedeniyle (Yunanistan’a uyuşturucu madde ithali olarak) Yunanistan’da mahkûm olmuşsa da; Y, bu fiil

Aynı yönde bir hükme yeni TCK'nın 188. maddesinde de yer verilmiştir:

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.” (f. 2).

Bu fıkranın **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir¹⁸:

“İkinci fıkrada, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarıyla ilgili olarak bir milletlerarası ceza hukuku kuralına yer verilmiştir. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilecektir. Türkiye’den yapılan uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı, karşı ülke açısından ithal oluşturmaktadır. Bu ülkede uyuşturucu veya uyarıcı madde ithali nedeniyle yargılama yapılması veya bir cezaya mahkûm olunması, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yargılama yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Böylece, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarıyla ilgili olarak non bis in idem kuralına milletlerarası sahada geçerlilik tanınmamıştır. Ancak, Türkiye’den yapılan uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı karşı ülke açısından ithal oluşturduğu için, bu ülkede yapılan yargılama sonucunda mahkûm olunan hapis cezasının kurumda infaz edilen kısmının, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılan yargılama sonucunda mahkûm olunan hapis cezasından mahsup edilmesi gerekmektedir.”

Türkiye’de işlenen fiille yurt dışında işlenen fiil, bir suçun seçimlik hareketlerini oluşturmayıp, bağımsız suç oluşturmakta iseler; bu durumda yabancı ülkede işlenen fiil dolayısıyla bu ülke mahkemelerinde dava açılmış olmasının, beraat veya mahkûmiyet kararı verilmiş olmasının ve hatta, hükmolunan cezanın infaz edilmiş olmasının ülkemizde işlenen fiil dolayısıyla Türkiye’de yargılama yapılmasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Yargıtay’ın da benzer yönde kararları bulunmaktadır:

«Uyuşturucu maddelere ilişkin TEK Sözleşmesinin 36/II-e maddesine göre; sanık hakkında, uyuşturucu madde satmak için bulundurmaktan Yugoslav adli makamlarınca mahkûmiyet kararı verilmiş olması; sanığın yurt dışına

nedeniyle Türkiye’de yeniden yargılanacaktır. Zira, fiil Türkiye’de işlenmiştir. Yabancı memlekette hüküm verilmiş olsa bile, bu fiilden dolayı K, Türkiye’de yeniden muhakeme edilecektir (TCK. m. 3, f. 1). Fakat, bu durumda yabancı ülkede mahkûm olup da infaz edilen ceza, Türkiye’de hükmolunacak cezadan mahsup edilecektir (TCK, m. 403, f. 4).

¹⁸ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 586 vd.

uyuşturucu madde ihraç etmesi eylemi dolayısıyla (mülga 765 s.) TCK'nın 3. maddesi muvacehesinde Türkiye'de yargılanmasına mani teşkil etmez.»¹⁹.

Yabancı ülkede işlenen fiilden dolayı mahkûm olunan ve bu ülkede infaz edilen ceza, Türkiye'de işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan cezadan mahsup edilemez. Nitekim, Yargıtay da aynı yönde karar vermiştir:

«Sanıkların suç konusu esrarı Türkiye'den ihraç etmelerinin ayrı bir suç teşkil ettiği gözetilmeden; Avustralya'daki mahkumiyetinin mahsubu ci-hetine gidilmesi» hukuka aykırıdır²⁰.

Yabancı asker kişilerin de ülkemizde işledikleri suçlardan dolayı Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere Türkiye'de yargılanmaları gerekir. Ancak, Kuzey Atlantik Anlaşması (NATO) çerçevesinde Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu asker kişilerle ilgili olarak bu prensibe istisnalar getirilmiştir. NATO üyesi devletler arasında 19 Haziran 1951 tarihinde Londra'da imzalanan Kuvvetler Statüsü Sözleşmesine göre, Gönderen Devletin²¹ askeri kanunlarına tabi kişilerin Kabul Eden Devletin ülkesinde *münhasıran* Gönderen Devletin güvenliğine, *münhasıran* Gönderen Devletin malına, *münhasıran* Gönderen Devletin personeline karşı işledikleri suçlardan dolayı Gönderen Devletin üstün yargı yetkisi bulunmaktadır (Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi, madde VII, bend 3, fıkra a/i). Keza, Gönderen Devletin askeri kanunlarına tabi kişilerin Kabul Eden Devletin ülkesinde “*resmi vazifenin ifası dolayısıyla*”²² işledikleri suçlarla ilgili olarak Gönderen Devlet üstün yargı yetkisini haiz bulunmaktadır (Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi, madde VII, bend 3, fıkra a/ii).

Bu durum karşısında, Gönderen Devletin askeri kanunlarına tabi kişilerin Kabul Eden Devlet olarak Türkiye'de işledikleri görevleriyle ilgili olmayan suçlardan dolayı Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere Türk mahkemelerinde yargılamaya yapılabilecektir²³.

¹⁹ 5. CD., 16.6.1983, 2332/2377 (Osman Yaşar, *Uygulamada Türk Ceza Yasası, Genel Hükümler*, Ankara, 2000, sh. 82/83). Aynı mealdeki kararlar için bkz. 5. CD., 3.2.1984, 283/318 (Osman Yaşar, *Uygulamada Türk Ceza Yasası*, sh. 82); 5. CD., 18.7.1985, 3718/3144 (Osman Yaşar, *Uygulamada Türk Ceza Yasası*, sh. 82); 10. CD., 13.4.1992, 4279/3766 (Osman Yaşar, *Uygulamada Türk Ceza Yasası*, sh. 84); 10. CD., 13.4.1992, 4280/3767 (Osman Yaşar, *Uygulamada Türk Ceza Yasası*, sh. 90/91).

²⁰ 5. CD., 30.4.1980, 1357/1488 (Osman Yaşar, *Uygulamada Türk Ceza Yasası*, sh. 102). Ayrıca bkz. 5. CD., 22.9.1979, 2374/2587 (Osman Yaşar, *Uygulamada Türk Ceza Yasası*, sh. 103).

²¹ Gönderen Devlet, genellikle Amerika Birleşik Devletleridir.

²² Ancak, belirtelim ki; Kuvvetler Statüsü Sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin 10.3.1954 t. ve 6375 s. Kanunda değişiklik yapan 16.7.1956 t. ve 6816 s. Kanunla Gönderen Devletin bu üstün yargı yetkisi “*resmi vazifenin ifası sırasında*” işlenen suçlara da teşmil edilmiştir. İlginçtir ki, bu kapsam değişikliği, Türkiye'nin aleyhine ve Sözleşmeye rağmen yapılmıştır.

²³ «Garnizon dışında ve askeri görevde olmaksızın bir Türk erinin bir Amerikan eri tarafından öldürülmesi hadisesinde Türk adli mahkemeleri vazifelidir.»: CGK., 27.11.1961, 67/65 (Osman Yaşar, *Uygulamada Türk Ceza Yasası*, sh. 81).

II. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Bakımından İlkeler

A. Faile Göre Şahsilik İlkesi

1) Görev Suçlarına İlişkin İlke

Yabancı ülkede Türkiye adına memuriyet veya sair bir görev üstlenmiş kişi, bu memuriyet veya göreviyle bağlantılı olarak suç işlemesi durumunda; Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere, Türkiye’de yargılanır. Bu konuda TCK’nın 10. maddesinde hüküm bulunmaktadır:

“Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsu bile, Türkiye’de yeniden yargılanır.”

Madde gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir²⁴:

“Maddeyle, yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev yapan kişilerin, yabancı memlekette bu memuriyet ve görevlerinden dolayı bir suç işlemleri hâlinde Türkiye’de yargılanacakları belirtilmiştir. Bu gibi memur ve görevliler hakkında yabancı ülkede yargılama yapılmış ve hüküm kurulmuş olması Türkiye’de suçun türüne, cezanın ağırlığına, suçtan zarar görenin uyuşuna ilişkin başkaca bir koşul aranmaksızın yeniden yargılama yapılmasına engel değildir. Ancak, bu durumda mahsup işlemlerinin uygulanacağı hususunda şüphe yoktur. Memuriyet veya görevin sürekli veya geçici olması, Devlet veya herhangi bir kamu kuruluşu adına yapılmış bulunması arasında fark yoktur.”

Bunun için, a) yurt dışında Türkiye “namına” memuriyet veya sair bir görev yapan kişi tarafından bir suç işlenmiş olması, b) işlenen suçun üstlenilen memuriyet ve görevle alakasının bulunması gerekir.

Yurt dışında Türkiye namına²⁵ memuriyet icra eden kişinin vatandaş olması gerekir (657 s. Devlet Memurları Kanunu, m. 48). Ancak, Türkiye adına görev

«Amerikan yardım heyetinde ve NATO’ya mensup askeri şahısların resmi görevleri sırasında işlenmeyen suçlardan dolayı yargı genel mahkemelere aittir.»: 3. CD., 18.5.1955, 9799/10663 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 82).

İzmir’deki Nato Askeri Üssünde görevli olan Amerikan askeri X, bir Temmuz akşamı Kordonboyu’nda gezerken 17 yaşındaki bayan Z’ye sarkıntılık eder.

Bu örnek olayda X, NATO sözleşmelerine göre Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeridir. Türk Mahkemelerinde sarkıntılık suçundan (TCK, m. 421) dolayı yargılanıp cezalandırılması gerekir. NATO Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi, X’in bu fiili dolayısıyla TCK hükümlerine istinaden cezalandırılmasına engel teşkil etmez. Zira, suç resmî görevin ifası sırasında veya resmî görevin ifası dolayısıyla işlenmemiştir (Bu örnek olayla ilgili olarak bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku(3), sh. 505, 510).

²⁴ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 412.

²⁵ Yurt dışında icra edilen memuriyet veya görevin, “Türkiye adına” olmasını dar yorumlamak gerekir. Bu itibarla, kanımızca Belediyeler ve hatta Kamu İktisadi Teşebbüsleri adına yurt dışında görev ifa eden kişileri de bu kapsamda mütalâa etmek gerekir. Aksi fikir için bkz.

yapan kişinin vatandaş olması gerekmez. Örneğin uluslararası yargı organları nezdinde Türkiye’yi temsil eden yabancı bir hukukçu, bu kapsamda mütalâa edilebilir²⁶. Madde gerekçesinde vurgulandığı üzere; bu “*memuriyet veya görevin sürekli veya geçici olması, Devlet veya herhangi bir kamu kuruluşu adına yapılmış bulunması arasında fark yoktur.*”

Yurt dışında Türkiye “namına” memuriyet veya sair bir görev yapan kişi, göreviyle bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu suçtan dolayı “*yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsa bile*”, Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere, Türkiye’de yargılanır. Bu kişi hakkında Türkiye’de Türk kanunlarına göre re’sen yargılama yapılacaktır.

Yabancı ülkede yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün örneğin beraat olması halinde, Türkiye’de bu suç nedeniyle yeniden yargılama yapıp yapılmaması tartışılabilir. Söz konusu madde metni Hükümet Tasarısından aynen iktibas edilmiştir. Yeni TCK’nın bu maddesine ilişkin olarak TBMM Adalet Alt Komisyonunda yapılan müzakereler sırasında bu sorun tarafımızdan gündeme getirilmiştir. Ancak, Komisyon, mahkûmiyet halinde aynı suç nedeniyle Türkiye’de yeniden yargılama yapılabildiğine göre, beraat veya örneğin zamanaşımının dolması nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi halinde evleviyetle yeniden yargılama yapılabilecektir düşüncesiyle, madde metninde herhangi bir değişiklik yapılmasını uygun görmemiştir.

Yabancı ülkede mahkûm olunan ceza eğer bu ülkede tamamen veya kısmen infaz edilmişse, infaz edilen bu ceza miktarının Türkiye’de hükmolunan cezadan mahsup edilmesi gerekir (m. 16)²⁷.

2) Vatandaş Tarafından İşlenen Suç

Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde suç işlemeleri durumunda; failer hakkında belli şartlarda Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılacaktır. Bu konuda Yeni TCK’nın 11. maddesinde düzenleme yapılmıştır:

DÖNMEZER/ERMAN: *Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku*, cilt III, 12. bası, İstanbul 1997, no. 2201; İÇEL/DONAY, sh. 177.

²⁶ ÖZGENÇ, *Yargıtay Dergisi*, cilt 28, Temmuz 2002, sayı 3, sh. 323 vd.; İÇEL/DONAY, sh. 177.

²⁷ Şöyle bir örnekle hükmün uygulanmasını daha iyi açıklayabiliriz:

M, Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosluğunda görevli bir memurdur. Alman makamlarının bir vatandaşımızın nüfus kayıtlarına ve medenî haline ilişkin olarak bilgi istemesi üzerine; bu konuda gerçeklerle bağdaşmayan bilgileri taşıyan bir belge düzenleyerek Alman makamlarına vermiştir. M, bu nedenle Almanya’da evrakta sahtekârlık suçundan dolayı 1 yıl hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmuştur.

M, yabancı devlette Türkiye namına memuriyet veya vazife deruhte eden bir kişidir. Memuriyet veya vazifesi dolayısıyla bir suç (evrakta sahtekârlık) işlemiştir. Bu suç dolayısıyla Almanya’da mahkûm olmuş ve cezası infaz edilmiş olsa bile, Türkiye’de yeniden yargılanır (765 s. TCK, m. 10). Ancak, yabancı memlekette mahkûm olup da infaz edilen cezanın aynı suç dolayısıyla Türkiye’de mahkûm olunan cezadan mahsup edecektir (Bu örnekle ilgili olarak bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN, *Uygulamalı Ceza Hukuku*, sh. 476, 479/480. Ayrıca bkz. İÇEL/DONAY, sh. 178/179).

“Bir Türk vatandaşı, 13'üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve Türkiye’de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre cezalandırılır.” (f. 1)

“Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar görenin veya yabancı hükümetin şikâyetine bağlıdır. Bu durumda şikâyet, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır.” (f. 2)

Bunun için aranan şartlar şunlardır:

- a) Suçun, yurt dışında, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik sahası dışında işlenmiş olması gerekir. Ancak, suçun işlendiği yerin yabancı bir devletin egemenlik sahasında olması gerekmemektedir. Bu bakımdan, suç örneğin açık denizlerde işlenmiş olabilir.
- b) Suçun bir *Türk vatandaşı* tarafından işlenmesi gerekir. Vatandaşlık, suç oluşturan fiilin işlendiği zamana göre belirlenecektir (m. 6, f. 1, bent [a])²⁸.
- c) Yurt dışında işlenen suçun, *“Türk kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suç”* olması gerekir²⁹. Bu şartın gerçekleşmesi halinde, fail hakkında Türkiye’de Türk kanunlarına göre *re’sen* yargılama yapılacaktır. Buna karşılık; yabancı ülkede işlenen suçun, Türk kanunlarına göre, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirmesi halinde; fail hakkında Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılabilmesi için, a) zarar gören şahsın veya b) yabancı hükümetin *şikâyetinin* olması gerekir (m. 11, f. 2). Ancak, *“bu durumda şikâyet, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır.”* (m. 11, f. 2, ikinci cümle).

Yeni TCK’ya ilişkin Hükümet Tasarısının düzenlemesine göre; yurt dışında işlenen ve Türk kanunlarına göre suç oluşturan fiilin aynı zamanda işlendiği ülke devleti kanunlarına göre de suç oluşturmaları gerekmektedir. Ancak, TBMM Adalet Komisyonunda madde metninde yapılan değişiklikte, bu madde

²⁸ Fransız CK’ya göre fiilin işlenmesinden sonra Fransız vatandaşlığının iktisap edilmiş olması halinde de, yurt dışında suçun vatandaş tarafından işlenmesine ilişkin hükümler uygulama kabiliyeti bulacaktır (22 Temmuz 1992 tarihli Fransız CK, m. 113-6, f. 3). Buna karşılık, mağdur bakımından fiilin işlendiği zaman Fransız vatandaşı olmak yeterli görülmektedir (Fransız CK, m. 113-7).

²⁹ Madde gerekçesinde bu hususla ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Hükümet Tasarısında vatandaş tarafından yurt dışında işlenen suçun hem Türk Kanunlarına göre hem de suçun işlendiği ülke kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olması öngörülmüştür. Ancak, bir sonraki maddede “yabancı tarafından işlenen suç” açısından ise sadece Türk Kanununda öngörülen ceza ölçü alınmıştır. Her iki durum açısından uyumu sağlamak için, sadece Türk Kanununda öngörülen cezanın ölçü alınması yönünde madde metninin değiştirilmesi uygun bulunmuştur.”

hükümünün uygulanabilmesi açısından, yurt dışında işlenen fiilin Türk kanunlarına göre suç oluşturması yeterli görülmüştür³⁰. Madde gerekçesinde yer verilen açıklamaya göre; mağdurun yabancı olması, bu düzenlemenin istisnasını oluşturmaktadır:

*“Türk vatandaşının yabancı ülkede işlediği suçtan dolayı mağdur olan kimse yabancı ise; fail hakkında Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılabilmesi için, fiilin, işlendiği ülke devleti kanununa göre de suç teşkil etmesi gerekir.”*³¹

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yeni TCK’nın 11. maddesi hükümlerine göre vatandaşın yurt dışında işlediği suçtan dolayı Türkiye’de yargılanabilmesi için, suçun yer aldığı kanun maddesinde münhasıran hapis cezası veya hapis cezası ile birlikte adli para cezasının öngörülmüş olması gerekir. Buna karşılık, “suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanması seçimlik sayılmış ise (başka bir ifadeyle, suçun kanuni tanımında hapis cezası ile adli para cezası **seçimlik ceza** olarak belirlenmiş ise, bu suç nedeniyle Türkiye’de) *soruşturma veya kovuşturma açılmaz.*” (m. 14).

d) Yurt dışında işlenen suçun, TCK’nın 13. maddesinde sayılan suçlardan olmaması gerekir. Zira, 13. madde kapsamına giren suçlar kim tarafından, nerede ve hatta kime karşı işlenmiş olurlarsa olsunlar; failleri, Türkiye’de, Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere yargılanabilirler.

e) Failin Türkiye’de bulunması gerekir. Failin Türkiye’de bulunmasının, bir *kovuşturma şartı*³² oluşturduğu, madde gerekçesinde açık bir şekilde vurgulanmıştır³³.

f) Yurt dışında işlenmiş olan suç nedeniyle Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için, failin Türkiye’de bulunmasının dışında, Türk kanunlarında aranan başka soruşturma ve kovuşturma şartlarının da gerçekleşmesi gerekir. Örneğin soruşturma ve kovuşturması mağdurun şikayetine bağlı bir suçtan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için, ayrıca şikayetin gerçekleşmesi gerekir (Bu

³⁰ Bu husus, madde gerekçesinin son paragrafındaki açıklamalardan açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

³¹ Doktrinde bazı yazarlar, gerekçede yer alan bu açıklamanın hiçbir hukuki değerinin olmadığını ileri sürmektedirler: ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, Dördüncü Bölüm, §1, II, 3, B; HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh.48 vd.

³² “Dava şartı” olduğu görüşü için bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 184. Bunu, bir “cezalandırılabilirlik şartı” olarak gören görüş (İÇEL/DONAY, sh. 192), kanımızca isabetli değildir. Nitekim, Yargıtay, çeşitli kararlarında bu şart gerçekleşmeden açılmış olan davalarla ilgili olarak durma kararı verilmesi gerektiğini belirterek, bizim benimsediğimiz görüşe taraftar olmuştur: 5. CD., 26.2.1992, 278/591 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 101); 5. CD., 21.3.1991, 556/1575 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 101)

³³ *Özbek*, Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için failin Türkiye’de bulunmasının bir koşul olarak aranmasına gerek olmadığını ileri sürmektedir: ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 3. bası, sh. 233 vd.

hususla ilişkin olarak yeni TCK'nın 102. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi örnek olarak gösterilebilir).

g) Yurt dışında işlenmiş olan suç nedeniyle Türkiye'de yargılama yapılabilmesi için, "bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması" gerekir³⁴.

Bu hususa ilişkin olarak madde **gereğince**de şu açıklamalar yer almaktadır³⁵:

"Bu suç dolayısıyla yabancı ülkede yargılama yapılmakta olsa bile, fail hakkında Türkiye'de Türk kanunlarına göre re'sen yargılama yapılacaktır.

Buna karşılık, yurt dışında işlediği suçtan dolayı Türk vatandaşı hakkındaki yabancı ülkede mahkûmiyet veya beraat kararının verilmiş olması hâlinde, artık Türkiye'de yeniden yargılama yapılamayacaktır."

Yeni TCK'nın söz konusu hükmüyle, bu hususla ilgili doktrin ve uygulamamızdaki tartışmalı³⁶ bir sorun³⁷ halledilmiş olmaktadır.

³⁴ Özbek, yeni TCK'da, kim tarafından işlenmiş olursa olsun, Türkiye'de işlenen suçlarla ilgili olarak non bis in idem kuralına geçerlilik tanınmamış iken; vatandaşın yurt dışında işlediği suçla ilgili olarak bu kurala geçerlilik tanınmasını bir "tutarsızlık" (?) olarak değerlendirmektedir: ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 3. bası, sh. 233 vd., 236.

³⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 412 vd.

³⁶ Bir görüşe göre, bu suç dolayısıyla yabancı ülkede hüküm verilmiş olsa bile, fail hakkında Türkiye'de Türk kanunlarına göre re'sen yargılama yapılacaktır. Bu hususta, yabancı ülkede yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün beraat veya mahkûmiyet olması arasında bir fark bulunmamaktadır: KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 11. bası, İstanbul 2000, sh. 497, dn. 73; İÇEL, Kayıhan: "Ne bis in idem" Kuralının Milletlerarası Değeri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt XXXVII, yıl 1972, sayı 1-4, sh. 399 vd. (408); ÖNDER, Ayhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler cilt I, İstanbul, Nisan 1991, sh. 226, 228; YENİSEY, Feridun: *Ceza Yargılamasının Milletlerarası Değeri* (Doçentlik Tezi), İstanbul 1982 (yayınlanmamıştır), sh. 180 vd; ÖZGENÇ, İzzet: *TCK'nın 5. maddesine İlişkin Yargıtay'ın İki Farklı Kararının İncelenmesi, Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Etkisi*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LI, yıl 1985, sayı 1-4, sh. 636 vd.

Bu görüş, Yargıtay'ın 6.4.1971 tarih ve 574/1209 sayılı Kararında benimsenmiştir (Karar metni için bkz. ÖZGENÇ, İstanbul ÜHFM LI(1985), sh. 627 vd.

Buna karşılık, diğer bir görüşe göre, Türk vatandaşının yabancı ülkede işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla bu ülkede yargılama yapılmış ve hüküm verilmiş ise; bu suç dolayısıyla fail hakkında Türkiye'de Türk kanunlarına göre yeniden yargılama yapılamaz. Bu hususta, yabancı ülkede yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün beraat veya mahkûmiyet olması arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu durumda non bis in idem kuralı Türkiye'de yeniden yargılamaya engel teşkil etmektedir: DÖNMEZER/ERMAN III, no. 2389, 2398; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, sh. 186; İÇEL/DONAY, sh. 184. Öztürk de, non bis in idem kuralının milletlerarası ceza hukukunda uygulama kabiliyeti bulması gerektiği yönünde bir temennide bulunmaktadır (ÖZTÜRK, *Uygulamalı Ceza Hukuku*, 4. bası, Ankara, 2000, sh. 57 vd). Daha eski görüşler için bkz. TANER, Tahir: *Ceza Hukuku Umumi Kısım*, İstanbul 1951, sh. 225; KUNTER, Nurullah: *Ceza Muhakemesi Hukuku*, 6. basısında kabul edilen görüş.

³⁷ Bu sorunla ilgili ayrıntılı açıklama için bkz. ÖZGENÇ, Yargıtay Dergisi, cilt 28, Temmuz 2002, sayı 3, sh. 323 vd.

Non bis in idem kuralı, iç hukukta geçerli olan bir kuraldır ve milletlerarası ceza hukukunda ancak istisnaen tatbik kabiliyeti bulur³⁸. Bu itibarla, ancak iki veya çok taraflı anlaşmalarla ya da devletin kendi iç yasal düzenlemeleri ile *non bis in idem* kuralına uluslararası bir değer vererek yeniden yargılama yoluna gidilmesinin önüne geçilebilecektir³⁹.

Bu itibarla, milletlerarası anlaşmalarla yabancı devlet mahkemelerinden verilmiş olan kararlara *non bis in idem* etkisi tanınmış olabilir⁴⁰.

Türkiye'nin taraf olduğu 28.5.1970 tarihli **Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi** (CYMDAS) (ETS 70)⁴¹ ile 15.5.1972 tarihli **Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi** (CKAAS) (ETS 73)⁴², *non bis in idem* kuralına milletlerarası ceza hukukunda da geçerlilik taşıyan değer izafe etmiştir.

Bu anlaşmalara göre, taraf devletlerden birinde bir suçla ilgili olarak bir şahıs hakkında *beraat* kararı verilmişse, bu durum mutlak olarak aynı kişinin aynı suçtan dolayı diğer taraf devlet mahkemelerinde yargılanmasına engel teşkil etmektedir (CYMDAS, m. 53, f. 1, bent a; CKAAS, m. 35, f. 1, bent a).

Taraf devletlerden birinde bir suçtan dolayı bir şahıs hakkında *mahkûmiyet* kararı verilmişse, yine aynı kişi aynı suçtan dolayı diğer taraf devlet mahkemelerinde yargılanamayacaktır. Ancak, bunun için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş bulunması gerekir (CYMDAS, m. 53, f. 1, bent b; CKAAS, m. 35, f. 1, bent b):

- 1) Taraf devletlerden biri mahkemelerince verilmiş olan mahkûmiyet kararı tamamen infaz edilmiştir veya halen infaz edilmektedir.
- 2) Mahkûmiyet kararında söz konusu edilen ceza, genel veya özel affa ya da zamanaşımına uğramıştır.

Taraf devlet mahkemesi, bir suçla ilgili olarak bir kişinin suçluluğunu tespit etmesine rağmen, henüz müeyyideyi tayin etmemiş olabilir. Bu durumda da, aynı kişi aynı suçtan dolayı diğer taraf devlet mahkemelerinde yargılanamayacaktır (CYMDAS, m. 53, f. 1, bent c; CKAAS, m. 35, f. 1, bent c)⁴³.

³⁸ JESCHECK, Lehrbuch(4), sh. 158.

³⁹ YENİSEY, Feridun: *Milletlerarası Ceza Hukuku*, İstanbul 1988, sh. 245/246; ÖZGENÇ, İstanbul ÜHFM LI(1985), sh. 637.

⁴⁰ TEZCAN, Durmuş: *Yurt Dışında İşlenen Suçlarda Türk Hukuku Bakımından Yabancı ceza Kanununun Değeri Sorunu*, in: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt XXXIX, yıl 1984, sayı 1-4, sh. 111 vd. (144 vd.).

⁴¹ Söz konusu Sözleşmenin onaylanması 1.3.1977 tarihli ve 2081 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Bakanlar Kurulu'nun 19.9.1977 tarihli ve 7/14157 sayılı Kararıyla onaylanan söz konusu Sözleşme metni **14 Aralık 1977 tarihli ve 16139 sayılı Resmi Gazetede** yayımlanmıştır.

⁴² Söz konusu Sözleşmenin onaylanması 1.3.1977 tarihli ve 2080 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Bakanlar Kurulu'nun 19.9.1977 tarihli ve 7/14153 sayılı Kararıyla onaylanan söz konusu Sözleşme metni **27 Aralık 1977 tarihli ve 16152 sayılı Resmi Gazetede** yayımlanmıştır.

⁴³ Ayrıca bkz. YENİSEY, *Milletlerarası Ceza Hukuku*, sh. 235.

Bu hükümlerden çıkarılan sonuç şudur: Bir suçtan dolayı taraf devletlerden birinde soruşturma başlatılmış veya yargılama süreci devam ediyor olsa bile; taraf devletlerden bir diğerinde aynı suçtan dolayı dava açılabilir. Ancak, bunun için, diğer taraf devlette daha önce açılmış olan davada suçun işlenip işlenmediğinin, işlenmişse kimin tarafından işlendiğinin henüz tespit edilmemiş olması gerekir. Bu tespit yapıldıktan sonra, artık *non bis in idem* kuralının gereği olarak, taraf devletlerden bir diğerinde aynı suç dolayısıyla aynı kişi hakkında yeniden dava açılmayacaktır⁴⁴.

⁴⁴ Olay. Türk vatandaşı olan A, Almanya’da eşine karşı işlemiş bulunduğu kasten yaralama suçundan dolayı Almanya’da yargılanır ve üç yıl hapis cezasına mahkûm edilir. Ancak, tutuklanmayan, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan A, bu cezanın infazına başlanmadan, kaçarak Türkiye’ye gelir.

Soru: Bu durumda;

- a) A, bu suç dolayısıyla Türkiye’de yeniden yargılanabilir mi?
- b) A, Almanya’da mahkûm olduğu cezanın infazı için Almanya’ya iade edilebilir mi?
- c) A’nın Almanya’da mahkûm edildiği cezanın infazı bakımından nasıl bir yol izlenebilir?
- d) A’nın Türkiye’ye geldikten sonra işlediği hırsızlık suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü kurulurken hakkında tekrerrür hükümleri uygulanabilir mi? Açıklayınız.

Cevap: a) TCK, m. 13 kapsamına giren suçlar hariç, bir Türk vatandaşının yurtdışında işlediği suç nedeniyle Türkiye’de Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere yargılanabilir (TCK, m. 11). Ancak bunun, için yurt dışında işlenen suçun belirli bir ağırlıkta olması gibi çeşitli koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bu çerçevede, yurt dışında işlediği suç sebebiyle vatandaş hakkında yabancı bir mahkemeden verilmiş mahkûmiyet veya beraat hükmünün olmaması gerekir.

Olayda, A, Almanya’da eşine karşı işlemiş olduğu kasten yaralama suçundan dolayı, bu ülke mahkemelerinde yargılanmış ve cezaya mahkûm edilmiştir.

TCK, m. 11 hükmüyle yurtdışında verilen beraat ve mahkûmiyet hükümlerine *non bis in idem* etkisi tanınmıştır. Ayrıca bu husus, Türkiye’nin taraf olduğu Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerle de düzenlenmektedir.

Bu nedenle A, Almanya’da eşine karşı işlemiş bulunduğu kasten yaralama suçundan dolayı Türkiye’de yeniden yargılanamaz.

b) Vatandaşın iade edilmesini yasaklayan Anayasa (m. 38, f. 12) ve 6706 sayılı **Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu** (m. 11, f. 1, bent a) hükümleri karşısında, A’nın mahkûm olduğu bu hapis cezasının infazı için Almanya ya iadesine hukuken imkan bulunmamaktadır.

c) A hakkında Almanya’da işlediği suç sebebiyle bu ülke mahkemelerince verilmiş olan hapis cezasının Türkiye’de infazı mümkündür. Bu konuda uluslararası adli iş birliği kurumlarından biri olan “infazın devralınması” kurumunun işletilmesi gerekmektedir. Infazın devralınması ve devredilmesi kurumları, hem Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi’nde, hem de Hükümlünün Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol ve Ek Protokolü Değiştiren Protokol’de düzenlenmektedir. Ayrıca Türk hukukunda, 6706 sayılı Kanunun 26 ilâ 29. maddeleriyle infazın devralınması ve devredilmesi kurumları düzenlenmektedir.

6706 sayılı Kanun’un “Infazın devralınması” başlıklı 26. maddesi hükmüne göre, yabancı devlet mahkemeleri tarafından verilen mahkûmiyet kararlarının Türkiye’de infazı mümkündür. Hükümlünün Türkiye’de bulunması; mahkûmiyet kararının kesinleşmiş olması; mahkûmiyet kararına konu fiilin Türk hukukuna göre suç teşkil etmesi ve zamanaşımına uğramamış olması; hürriyeti bağlayıcı cezalar için, merkezî makamlarca aksi kararlaştırılmadıkça talep tarihinde, hükümlünün ceza infaz kurumunda infazı gereken en az altı ay hürriyeti bağlayıcı cezasının bulunması; aynı suçtan dolayı Türkiye’de soruşturma veya kovuşturma yapılmamış olması durum-

Söz konusu Sözleşmelere taraf olan devletlerden birinde, bu devlet ülkesinde işlenmiş bir suçla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olmakla birlikte, bu soruşturma sonucunda meselâ *kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı* verilmiş ise, yani savcılık tarafından dava açılmaması yönünde bir karar verilmiş ise; bu durumda, *non bis in idem* kuralının milletlerarası geçerliliğinden artık söz edilemez. Bu itibarla, yabancı ülkede işlediği bir suç dolayısıyla, suçun işlendiği ülkede *kovuşturmaya yer olmadığı* kararı verilmiş olsa bile, bu suçu işleyen Türk vatandaşı hakkında Türkiye’de dava açılacaktır⁴⁵.

larında yabancı devlet mahkemesince verilmiş hüküm Türkiye’de infaz edilebilecektir. Bu bağlamda, A’nın Almanya’da mahkûm edildiği cezanın infazı için, Almanya tarafından infazın devri talebinde bulunulması ve 6706 sayılı Kanun’da belirtilen koşulların gerçekleşmesi gerekir. Olayda A bakımından, Kanun’daki bu şartlar gerçekleşmiş gözükmektedir.

İnfazın devri talebinde bulunulması hâlinde, 6706 s. Kanun, m. 26, f. 2 hükmüne göre, yabancı devlet makamlarından çeşitli belgeler talep edilecektir. Devir koşullarının bulunmadığının tespit edilmesi veya devrin Türkiye’nin millî güvenliği ile temel çıkarlarına uygun düşmeyeceğinin anlaşılması hâlinde, devir talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedilir. (6706 s. Kanun, m. 26, f. 3) Ayrıca, 6706 s. Kanun, m. 26, f. 5 hükmü uyarınca infazın devrine ilişkin talep, Türk hukukuna göre uyarılma kararı verilmesi için Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilir. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından on beş gün içinde, yabancı devlette verilen mahkûmiyet kararında sübutu kabul edilen fiile, Türk kanunlarına göre verilmesi gereken ceza tayin olunur. Bu suretle belirlenen ceza, yabancı mahkeme kararında tayin edilmiş ceza süresini geçemeyecektir. Sonrasında verilen uyarılma kararı, Alman makamlarına bildirilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilir (6706 s. Kanun m. 26, f. 6). Yabancı devletin infazı devretmesi üzerine ise durum, uyarılma kararını veren mahkemeye bildirilir ve Mahkeme infaza başlanması için kararı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir. Mahkeme ayrıca kararı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bildirir (6706 s. Kanun, m. 27, f. 1).

d) Tekerrür hükümlerinin uygulanmasında, kural olarak Türk mahkemelerinden verilen mahkûmiyetler esas alınır. Ancak yabancı devlet mahkemeleri tarafından verilmiş olan belirli suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, tekerrür hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır. Bu istisnai suçlar, **kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçlarıdır** (TCK, m. 58, f. 4).

Olayda A hakkında kasten yaralama suçundan dolayı Almanya’da verilen mahkûmiyet hükmü, Türkiye’ye geldikten sonra işlediği hırsızlık suçundan dolayı mahkûmiyet hükmü kurlurken tekerrür hükümlerinin uygulanmasında esas alınacaktır.

⁴⁵ Sanık L’nin Türk vatandaşı olan A’yı Norveç’te öldürmesi dolayısıyla Norveç Kraliyet Savcılığıınca “olayda *meşru müdafaa*nın bulunduğu kabul edilerek *takipsizlik kararı*” verilmesi gözönünde tutularak; Uşak Ağır Ceza Mahkemesi’nce “kamu davasının reddine” karar verilmiş(tir. Ancak,) “non bis in idem” kuralı gereğince, aynı fiilden iki defa cezalandırmayı engelleyebilmek için, yabancı ülkede verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli sayılması gerekmektedir birlikte, TCK’nın 5. maddesi açıklığı karşısında takipsizlik kararlarının, yabancı ülkede mahkûm olmadan Türkiye’ye gelen sanıkların Türk kanunlarına göre yargılanıp cezalandırılmalarını engellemeyeceği ve 15.2.1972 tarihli “*Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması Konusundaki Avrupa Sözleşmesi*”nin (RG.: 27.12.1977/16157) 35. maddesi hükmü göz önünde tutularak yargılamaya devamla sanık L hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.»: 1. CD., 25.1.1990, 84/35 (YKD, Mayıs 1990, sh. 741).

Keza, ... Deniz Nakliyat Şirketine ait Türk bandıralı ticaret gemisi *İrlanda*’nın Cork Limanında bağlı iken, gemi içerisinde bir T.C. vatandaşının diğer bir T.C. vatandaşını öldürmesi hadisesine

Yargıtay'ın bu konudaki içtihatları arasında istikrar bulunmamaktadır. Bu hususa ilişkin olarak, Yargıtay son zamanlarda şu içtihatla bulunmuştur:

«Federal Almanya'nın ... Kentinde ... alıcı kılığındaki Alman Polisi(ne) ... ticaret amacıyla bulundurduğu ve (fakat) Türkiye'den ihraç etmediği ... 100 gram kokaini satıp ... teslim e(den) ... F'nin, Federal Almanya ... Mahkemesi'nin ... kararı ile ... hapis cezasına mahkûm edil(miş) ... olmasına göre; yabancı ülkede (765 s.) TCK'nın 4. maddesinde yazılı suçlar dışında bir suç işlemiş ve hakkında o ülkede hüküm verilmiş kişinin Türkiye'de yeniden yargılanacağı hususunda anılan Kanunun 5. maddesinde açıkça bir hüküm bulunmadığı cihetle; "non bis in idem" kuralı uyarınca sanığın Türkiye'de yeniden yargılanması mümkün değildir.»⁴⁶

Yargıtay'ın söz konusu içtihadında varılan sonuç, bu iki Sözleşmeye (CYM-DAS ve CKAAS) taraf olan devletlerde işlenen suçlar açısından doğrudur. Ancak, belirtmek gerekir ki; Yargıtay'ın nakletmiş bulunduğumuz kararına konu teşkil eden suçun işlendiği ülke olan Almanya, kararın verildiği tarih itibarıyla söz konusu sözleşmelerin hiçbirini onaylamamıştır. Yargıtay, bu sonuca, *non bis in idem* kuralının milletlerarası sahada da kural olarak geçerli olduğu; ancak buna, 765 s. TCK'nın 4. maddesinin ikinci fıkrasında olduğu gibi, kanunla sınır-lama getirilebileceği gerekçesiyle ulaşmaktadır. Bu gerekçe de, doğru değildir.

Ayrıca belirtelim ki; yeni TCK'nın 16. maddesi hükmü karşısında; yabancı ülkede mahkûm olunan ceza eğer bu ülkede tamamen veya kısmen infaz edilmişse; infaz edilen bu ceza miktarının Türkiye'de hükmolunan cezadan mahsup edilmesi gerekir.

B. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi

Türk vatandaşı olmayan bir kimse tarafından yabancı bir ülkede bir suç işlenmesi durumunda, fail hakkında belli şartlarda Türkiye'de Türk kanunlarına göre yargılama yapılacaktır. Bu konuda yeni TCK'nın "*Yabancı tarafından işlenen suç*" başlıklı 12. maddesinde düzenleme yapılmıştır:

«Bir yabancı, 13'üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı

ilişkin olarak Yargıtay, «"Non bis in idem" kuralı gereğince ancak yabancı ülkede verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarının Türk Yargısını bağlayacağı, savcılık kararlarının bağlayıcı olmayacağı» doğrultusunda karar vermiştir: 1. CD., 12.10.1992, 1605/2165 (YKD, Ocak 1993, 116-118).

⁴⁶ 10. CD., 22.12.1992, 14669/13273 (YKD, Nisan 1993, sh. 639). Aynı yönde kararlar için bkz. 10. CD., 15.10.1996, 10720/10760 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 89); 5. CD., 1.2.1983, 47/282 (Savaş/Mollamahmutoğlu I[3], sh. 202; Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 102); 5. CD., 8.7.1982, 2760/2779 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 102); 5. CD., 14.6.1982, 2880/2436 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 83, 88); 5. CD., 24.1.1969, 305/224 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 103); 1. CD., 10.4.1987, 860/1181 (YKD, Ağustos 1987, sh. 1238); 1. CD., 19.9.1987, 2711/3090 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 99/100); 1. CD., 30.1.1980, 4997/309 (YKD, Nisan 1980, sh. 585).

ülkede Türkiye'nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır.” (f. 1)

“Yukarıdaki fıkra da belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve failin Türkiye'de bulunması hâlinde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine, fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır.” (f. 2)

“Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı hâlinde fail, Adalet Bakanının istemi ile yargılanır:

a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis cezasını gerektirmesi,

b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükûmeti tarafından kabul edilmemiş olması.” (f. 3)

“Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece mahkûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır.” (f. 4)

“Birinci fıkra kapsamına giren hâllerde rüşvet ve nüfuz ticareti suçlarından dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlı değildir.” (f. 5)

Yeni TCK'nın 12. maddesinin birinci fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

a) Suçun, yurt dışında, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik sahası dışında işlenmiş olması gerekir.

b) Suçun, Türk vatandaşı olmayan bir kimse, yani yabancı tarafından işlenmiş olması gerekir.

c) Yurt dışında işlenen suçun, “Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suç” olması gerekir.

d) Yabancı ülkede işlenen suçun “Türkiye'nin zararına” işlenmesi gerekir. Ancak, bu suçun, TCK'nın 13. maddesinde sayılan suçlardan olmaması gerekir. Bu itibarla, yabancı ülkede işlenen suçun, örneğin devletin güvenliğine karşı işlenen bir suç olması, ya da, Türk parasına veya Türkiye'ye ilişkin mühür ve damgalarda sahtekârlık suçunu oluşturması halinde, sorunu 13. madde kapsamında değerlendirmek gerekir.

e) Failin Türkiye'de bulunması gerekir. Failin Türkiye'de bulunması, bir kovuşturma şartı oluşturmaktadır.

Bütün bu şartların gerçekleşmesi halinde, kural olarak, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yargılama yapılabilecektir.

Ancak, yabancı tarafından işlenen yurt dışında Türkiye’nin zararına olarak işlediği suçun, TCK’nın 252. maddesinde tanımlanan rüşvet veya 255. maddesinde tanımlanan nüfuz ticareti suçu olması halinde, yabancı hakkında Adalet Bakanının talebine gerek olmadan, re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir⁴⁷.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yeni TCK’nın 12. maddesi hükümlerine göre yabancının yurt dışında işlediği suçtan dolayı Türkiye’de yargılanabilmesi için, suçun yer aldığı kanun maddesinde münhasıran hapis cezası veya hapis cezası ile birlikte adli para cezasının öngörülmüş olması gerekir. Buna karşılık, “suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanması seçimlik sayılmış ise (başka bir ifadeyle, suçun kanuni tanımında hapis cezası ile adli para cezası **seçimlik ceza** olarak belirlenmiş ise, bu suç nedeniyle Türkiye’de) soruşturma veya kovuşturma açılmaz.” (m. 14).

Yabancı kişi tarafından “Türkiye’nin zararına” işlenmiş olan suç dolayısıyla suçun işlendiği ülkede yargılama yapıp bir hüküm verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de Türk kanunlarına göre yeniden yargılama yapılabilecektir. Bu husus, söz konusu madde gerekçesinde açık bir şekilde

⁴⁷ 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla 12. madde metnine eklenen beşinci fıkra hükmü bağlamında, Kanun Tasarısında **gerekçe** olarak şu açıklamalara yer verilmiştir (TBMM, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 4, Sıra Sayısı: 592, sh. 20):

“Türk Ceza Kanununun 12’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, bir yabancının Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren ve 13’üncü maddede sayılanlar haricindeki bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlemesi ve Türkiye’de bulunması halinde Türkiye’de yargılama yapılabilmesi Adalet Bakanının istemine bağlıdır.

Kanunun “Rüşvet” suçunu düzenleyen 252’nci maddesinin onuncu fıkrası gereğince bir yabancının Türkiye zararına olarak dokuzuncu fıkradaki görevleri ifa eden yabancılara rüşvet vermesi eylemi Türkiye’de resen yargılama konusu yapılmaktadır. Ancak, bir yabancının bir Türk vatandaşı kamu görevlisine yabancı ülkede rüşvet vermesi eyleminde ise yabancı hakkında Kanunun 12’nci maddesi gereğince Adalet Bakanının istemi halinde soruşturma ve kovuşturma yapılabilmektedir.

Başka bir ifadeyle mevcut duruma göre, yabancı bir ülkede bir yabancının Türkiye zararına başka bir yabancıya rüşvet vermesi, teklif etmesi, aracılık etmesi eylemleri resen soruşturulurken, Türk vatandaşına rüşvet vermesi, teklif etmesi, aracılık etmesi durumunda yabancının eylemi ancak Adalet Bakanının istemiyle yargılama konusu yapılabilmektedir.

Öte yandan, 5/2/2004 tarihli ve 2004/6771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin “Yetki” başlıklı 17’nci maddesinde bu şekilde bir izin sistemine yer verilmemiştir.

Maddeye eklenen fıkrayla, yabancı ülkede bir yabancının Türk kamu görevlisine rüşvet vermesi durumunda yabancı bakımından Türkiye’de resen soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Aynı şekilde nüfuz ticareti suçu bakımından da Adalet Bakanının istemi aranmayacaktır.”

vurgulandığı gibi; TBMM Adalet Komisyonunda yapılan değişiklikle madde metnine eklenen dördüncü fıkrada, ayrıca düzenlenmiştir:

“Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece mahkûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye’de yeniden yargılama yapılır.”

İşlenen suçtan dolayı yabancı devlet mahkemesinde bir cezaya mahkûmiyet halinde, 16. madde hükmünün gereği olarak, yabancı ülkede infaz edilmiş olan ceza miktarı, Türkiye’de hükmolunacak olan cezadan mahsup edilecektir⁴⁸.

Söz konusu 12. maddenin ikinci fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

- a) Suçun, yurt dışında, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik sahası dışında işlenmiş olması gerekir.
- b) Suçun, Türk vatandaşı olmayan bir kimse, yani *yabancı* tarafından işlenmiş olması gerekir.
- c) Yurt dışında işlenen suçun, “Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suç” olması gerekir.
- d) Yabancı ülkede işlenen suçun “bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına” işlenmesi gerekir.

Madde **gereğince** bu hususla ilgili olarak şu açıklamaya yer verilmiştir:

“Tasarı maddesinin ikinci fıkrasında “... bir Türk’ün” ifadesinden sonra gelmek üzere, “veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin” ifadesine yer verilmiştir. Bu değişiklikle, yabancı tarafından yurt dışında Türk Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin zararına olarak

⁴⁸ Şöyle bir örnekle hükmün uygulanmasını daha iyi açıklayabiliriz:

X, Hollanda vatandaşıdır. Çeşitli sebeplerle Hollanda’da bulunan vatandaşlarımızın “nevruz” günü münasebetiyle 21 Mart 1996 tarihinde Amsterdam kentinde yaptıkları gösteriler sırasında bu şehirde bulunan ülkemize ait elçilik, konsolosluk binalarıyla, THY bürosuna ve Ziraat Bankası şubesine taş ve sopalarla saldırmışlar; binalara ve içindeki eşyaya büyük ölçüde zarar vermişlerdir. X ve diğer vatandaşlarımız, bu nedenle Hollanda’da yargılanmışlar ve neticede birer yıl hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmuşlardır. X, cezası infaz edildikten sonra yaz tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelmiştir.

X, bir yabancısıdır. Hollanda’da bulunan diğer vatandaşlarımızla birlikte bu ülkede Türkiye’nin zararını doğuracak mahiyette suç işlemişlerdir. Bu kişi Türkiye’de bulunduğu takdirde ve Adalet Bakanının talep etmesi halinde Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

Bu fiiller dolayısıyla X Hollanda’da mahkûm olsa ve cezası infaz edilse bile, Türkiye’de yeniden yargılanabilecektir. Ancak, bu durumda yabancı devlette infaz edilen ceza, Türkiye’de mahkûm olunan cezadan mahsup edilir. (Bu örnekle ilgili olarak bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN, Uygulamalı Ceza Hukuku, sh. 470, 475)

suç işlenmesi durumunda da, Türk Kanunlarının uygulanmasına imkan sağlanmıştır.”

e) Failin Türkiye’de bulunması gerekir. Failin Türkiye’de bulunması, bir kovuşturma şartı oluşturmaktadır.

f) Birinci fıkra hükmünden farklı olarak; yurt dışında işlenmiş olan suç nedeniyle Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için, *“bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması”* gerekir.

Bütün bu şartların gerçekleşmesi halinde, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine Türkiye’de yargılama yapılabilir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, yabancı tarafından yurt dışında işlenen suçun mağdurunun yabancı olması halinde Türkiye’de yargılama yapılabilmesinin şartları belirlenmiştir.

765 s. Kanunun 6. maddesinde olduğu gibi, bu durumda Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için;

“a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis cezasını gerektir(en bir suç olması ve),

b) (Suçun işlendiği ülke devleti ile Türkiye arasında) suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükûmeti tarafından kabul edilmemiş olması” gerekir.

Bu şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, *“Adalet Bakanının istemi”* üzerine Türkiye’de yargılama yapılabilir.

C. Evrensellik ve Koruma İlkesi

Evrensellik ve koruma prensibiyle ilgili olarak yeni TCK’nın **“Diğer suçlar”** başlıklı 13. maddesinde düzenleme yapılmıştır:

“Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi hâlinde, Türk kanunları uygulanır.

a) İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar,

b) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerde yer alan suçlar,

c) İşkence (madde 94, 95),

d) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181),

e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

f) *Parada sahtecilik (madde 197), para ve kıymetli damgaları imale yayan araçların üretimi ve ticareti (madde 200), mühürde sahtecilik (madde 202),*

g) *Fuhuş (madde 227),*

h) ...⁴⁹

i) *Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması (madde 223, fıkra 2, 3) ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme (madde 152) suçları.” (f. 1)*

“İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı Türkiye’de yargılama yapılması, Adalet Bakanının talebine bağlıdır.” (f. 2)⁵⁰.

“Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yargılama yapılır.” (f. 3)⁵¹.

Madde gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir⁵²:

“Madde metninde, belli suçların yabancı bir ülkede işlenmesi durumunda, failin Türk vatandaşı veya yabancı olmasına bakılmaksızın, Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Birinci fıkranın (a) bendine göre, İkinci Kitap, Birinci Kısım altındaki

1) “Soykırım ve İnsanlığa karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümde,

2) “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” başlıklı İkinci Bölümde

yer alan suçlar ile;

(b) bendine göre, İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki

⁴⁹ Bu bent, 26.6.2009 tarihli ve 5918 sayılı Kanunla (RG: 9 Temmuz 2009/27283), yürürlükten kaldırılmıştır (m. 1).

⁵⁰ 27.5.2005 tarihli ve 5357 sayılı Kanunla yeni TCK’nın 13’üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından söz konusu Kanun bir daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına iade edilmiştir. Bu iade kapsamında Cumhurbaşkanlığı makamının yeniden görüşülmesini istediği maddelerden biri de, TCK’nın 13’üncü maddesine yeni bir fıkra eklenmesine ilişkin çerçeve üçüncü maddedir.

Bu iade üzerine, söz konusu değişiklik Kanunu, TBMM’de bir daha görüşülmüş ve TCK’nın 13’üncü maddesine yeni bir fıkra eklenmesine ilişkin çerçeve üçüncü madde, herhangi bir değişiklik yapılmadan 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla yeniden kabul edilmiştir.

⁵¹ 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmesinin yanı sıra, fıkra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir. Bu nedenle, söz konusu fıkra numarası “2” iken, “3” olarak değiştirilmiştir (5377 s. K, m. 3).

⁵² TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 416 vd.

- 1) “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlıklı Üçüncü Bölümde,
- 2) “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Bölümde,
- 3) “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci Bölümde,
- 4) “Millî Savunmaya Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölümde,
- 5) “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” başlıklı Yedinci Bölümde ve
- 6) “Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar” başlıklı Sekizinci Bölümde

yer alan suçlar ile, fıkranın (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan suçlar nerede işlenmiş olursa olsun, bu nedenle Türkiye’de yargılama yapılarak, Türk vatandaşı veya yabancı olmasına bakılmaksızın fail hakkında Türk kanunlarına göre cezaya hükmolunur. Yabancı ülkede işlenen bu suçlar dolayısıyla failler hakkında Türkiye’de re’sen takibat yapılır.

Maddenin ikinci⁵³ fıkrasına göre, bu suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Türkiye’de yeniden yargılama yapılır. Ancak bunun için Adalet Bakanının talepte bulunması gerekir.

Yabancı ülkede mahkûm olunan ceza bu ülkede tamamen veya kısmen infaz edilmişse; infaz edilen bu ceza miktarının, mahsup hükümlerine göre, Türkiye’de hükmolunan cezadan mahsup edilmesi gerekir.

Birinci fıkranın (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde; bu suç dolayısıyla, suçu işleyen kişinin Türk vatandaşı veya yabancı olması arasında fark gözetmeksizin, Türkiye’de Türk kanunları uygulanarak yargılama yapılabilir.

Ancak, (a) ve (b) bentlerinden farklı olarak, bu bentlerde sayılan suçlardan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için, fail hakkında yabancı ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmemiş olması gerekir.

Türkiye’nin taraf olduğu çeşitli uluslararası sözleşmelerde aut dedere aut judicare/aut punire kuralına yer verilmek suretiyle ilgili sözleşme kapsamına giren suçlar dolayısıyla ister vatandaş olsun ister yabancı olsun faillerin suçun işlendiği ülkeye geri verilmesi öngörülmüştür. Ancak, bu sözleşmelerle, çeşitli hukuki mülahazalarla geriverme yoluna gidilmemesi hâlinde, taraf devletlere yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü yüklenmiştir.

⁵³ Bir önceki dipnotta belirtilen nedenle, söz konusu atfı **üçüncü fıkraya** yapılmış yollama olarak anlamak gerekir.

Bu konuda, 1963 yılında imzalanan Uçaklara Karşı İşlenen Suçlara veya Diğer Fillere İlişkin Tokyo Sözleşmesi, 1970 yılında imzalanan Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi hakkındaki La Haye Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi, 14 Aralık 1973 tarihli Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair New York Sözleşmesi, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi, 21.12.1971 tarihinde Viyana’da imzalanan Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve ayrıca, Avrupa Konseyi’nce 27.01.1977 tarihinde hazırlanan Tedhişçiliğin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi örnek olarak gösterilebilir.”

27.5.2005 tarihli ve 5357 sayılı Kanunla yeni TCK’nın 13’üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından söz konusu Kanun bir daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına iade edilmiştir. Bu iade kapsamında Cumhurbaşkanlığı makamının yeniden görüşülmesini istediği iki maddeden biri, TCK’nın 13’üncü maddesine yeni bir fıkra eklenmesine ilişkin çerçeve 3’üncü maddedir.

Bu iade üzerine, söz konusu değişiklik Kanunu, TBMM’nde bir daha görüşülmüş ve TCK’nın 13’üncü maddesine yeni bir fıkra eklenmesine ilişkin çerçeve 3’üncü madde, herhangi bir değişiklik yapılmadan 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla yeniden kabul edilmiştir.

TCK’nın 13’üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen bu ikinci fıkranın **gerekçesi** şu şekildedir:

“Kanunun 13’üncü maddesinde sayılan belli suçlardan dolayı, kim tarafından, nerede ve hatta, kime karşı işlenmiş olursa olsun, Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılabilecektir.

Ancak, bu suçlardan bir kısmıyla ilgili olarak ‘kamu davasının açılmasında mecburilik kuralı’nın benimsenmesi, bazı durumlarda politik bir sorun ortaya çıkarabilecek bir mahiyet taşımaktadır. Bu nedenle, madde metnine ikinci fıkra olarak eklenen bu hükümle, maddede yer alan ve birinci fıkranın (b) bendinde sayılanlar dışındaki diğer suçlardan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi Adalet Bakanının talebine bağlı tutulmuştur.”⁵⁴

Ancak, 03/06/2005 tarih ve B.01.0.KKB.01-18/A-8-2005-451 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile bu değişiklik yerinde görülmeyerek, söz konusu Kanun bir daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına iade edilmiştir.

⁵⁴ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 901, sh. 2.

Bu geri gönderme yazısında ileri sürülen **gerekçeler** şunlardır:

«İncelenen Yasa'nın 3. maddesiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 13. maddesine eklenen 2. fıkra da,

"(2) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılması, Adalet Bakanının talebine bağlıdır.",

denilmiş; buna bağlı olarak maddenin (2). fıkrası da (3). fıkra olmuştur.

Düzenlemeyle, fıkra belirtilen ayrıklıklar dışında, yabancı ülkede işlenen,

- İkinci Kitap, Birinci Kısım altındaki "Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti",

- İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Sekizinci Bölümde yer alan "Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar",

- İşkence, çevrenin kasten kirletilmesi, uyuşturucu ya da uyarıcı madde üretim ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, parada sahtecilik, para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçların üretimi ve ticareti, mühürde sahtecilik, fuhuş, rüşvet, deniz, demiryolu ya da havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması, alıkonulması ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme suçları,

nedenleriyle, Türk yurttaşı olup olmadığının bakılmaksızın failin Türkiye'de yargılanabilmesi Adalet Bakanı'nın istemine bağlı tutulmuştur.

Madde gerekçesinde, Adalet Bakanı'na bu yetkinin verilmesi, sayılan suçlardan bir kısmıyla ilgili olarak "kamu davasının açılmasında zorunluluk kuralı"nın benimsenmesinin, kimi durumlarda politik bir sorun yaratabilecek nitelikte olmasına bağlanmıştır.

Madde gerekçesinden de açıkça anlaşıldığı gibi, fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı failin Türkiye'de yargılanabilmesi Adalet Bakanı'nın takdirine bırakılmıştır. Bu yetkinin yaratacağı sonuca göre, yurt dışında aynı suçu işleyen iki kişiden biri Adalet Bakanı'nın istemi üzerine Türkiye'de yargılanacak, diğeri, istemde bulunulmazsa yargılamadan kurtulabilecektir.

Gerek 765 sayılı önceki Türk Ceza Yasası'nın 4., gerek 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 13. maddelerinde, Devlet'in yabancı bir ülkede suç işleyen "yurttaşını" cezalandırması, "suç failine göre kişiselilik" ilkesi gözönünde tutularak düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerin amacı, yabancı ülkede suç işleyen, ancak kendi ülkesine döndüğü için ve "yurttaşların verilmemesi ilkesi" nedeniyle suçu işlediği ülkede cezalandırılmayan kişinin, kimi koşullarla ülkesinde ceza-

landırılmasını sağlamaktır. Böylece, nerede işlenirse işlensin hiçbir suç cezasız kalmayacaktır.

Bununla birlikte, 765 sayılı önceki Türk Ceza Yasası'nın 6. maddesinde, incelenen Yasa'nın 3. maddesiyle getirilen sistemden farklı biçimde, yabancı ülkede, Türkiye ya da Türk yurttaşının zararına cürüm işleyen "yabancıların" Türkiye'de yargılanabilmesi, diğer koşulların yanında Adalet Bakanı'nın istemine bağlı kılınmış, suçun bir Türk yurttaşınca işlenmesi durumu öngörülmemiştir.

Oysa, incelenen Yasa'nın 3. maddesiyle getirilen düzenlemede, Türk-yabancı ayrımı yapılmaksızın, fıkra da belirtilen suçlar nedeniyle Türkiye'de yargılama yapılabilmesi Adalet Bakanı'nın istemine bağlanmıştır.

Gerçi, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 13. maddesinin 2. fıkrasında, yabancı bir ülkede işlediği suç nedeniyle o ülkede yargılanan kişilerin Adalet Bakanı'nın istemiyle Türkiye'de yeniden yargılanabilmelerini olanaklı kılan bir kural vardır. Ancak, bu kural, bir kişinin aynı suçtan ikinci kez yargılanmaması ilkesine karşın, fıkra da sayılan suçların önemi nedeniyle, Devlet'in egemenlik hakkı gözetilerek getirilmiştir.

İncelenen Yasa'nın 3. maddesiyle eklenen 2. fıkra kuralında ise, kapsama giren suçları işleyen kişilerin Türkiye'de yargılanmaları Adalet Bakanı'nın istemine bağlı tutulurken, suçun önemi gözönünde bulundurulmadığı gibi, failin ya da faillerin yabancı ülkede yargılanıp yargılanmadıklarına da bakılmamaktadır.

Başka bir anlatımla, 5237 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin 2. fıkrasında tanınan istemde bulunma yetkisinin kullanılmaması durumunda, kişi ikinci kez yargılanmamış olacak; buna karşılık, incelenen Yasa ile getirilen 2. fıkradaki istemde bulunma yetkisinin kullanılmaması durumunda ise, kişi hiç yargılanmamış olacaktır.

Bu nedenle her iki fıkra da Adalet Bakanı'na tanınan yetkiler arasında önemli fark bulunmaktadır.

İncelenen Yasa'yla getirilen, failin yargılanmasını ve cezalandırılmasını Adalet Bakanı'nın, siyasi ve öznel olarak kullanılabilecek biçimde takdirine bırakan düzenlemenin ayrıcalık niteliğinde olduğu ortadadır.

Anayasa'nın 2. maddesinde, hukuk devleti ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri arasında sayılmış; 10. maddesinde de, herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayırım gözetilmeksizin yasa önünde eşit olduğu; hiçbir kişiye, aileye, zümreye ya da sınıfa ayrıcalık tanınamayacağı, Devlet organları ve yönetimin tüm işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunda oldukları kurala bağlanmıştır.

Hukuk devleti, Anayasa Mahkemesi'nin pek çok kararında belirtildiği gibi, insan haklarına dayanan, hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı tutum ve durumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa koyucunun bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğu bilincinde olan devlettir.

Hukuk devleti ve eşitlik ilkeleri, hangi nedenle olursa olsun hiç kimsenin hukukun üstünde tutulmamasını, ceza yönünden sorumsuzluk durumlarının belli bir amacın gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, suç failleri arasında farklılık yaratmayacak ve sınırlı biçimde getirilmesini gerektirmektedir.

Yabancı ülkede işlenmiş olsa da, kimi suçlardan dolayı kişiler için, Adalet Bakanı'nın takdirine dayalı olarak getirilen sorumsuzluk durumunun, hukuka aykırı ayrıcalık olduğu, eşitsizlik yarattığı ve hukuk devletinde bu tür ayrıcalıklara ve eşitsizliklere yer verilemeyeceği açıktır.

Bu nedenle, incelenen Yasa'nın 3. maddesiyle yapılan düzenleme hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmamakta, toplumun adalet duygularını incitecek nitelikte bulunmaktadır.»⁵⁵.

TBMM Başkanlığına iade edilen bu Kanun TBMM Adalet Komisyonunda yeniden görüşülmüş ve iade nedenlerinden birini oluşturan bu madde, herhangi bir değişiklik yapılmadan aşağıdaki **gerekçe**yle aynen kabul edilmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı makamının söz konusu geri gönderme yazısında, 27.5.2005 tarihli ve 5357 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile Türk Ceza Kanununun 13'üncü maddesine ikinci fıkra olarak eklenen hükmün Anayasanın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Söz konusu yazıda yer alan gerekçede, Türk Ceza Kanununun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasına getirilen istisna kapsamındaki suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılmasının Adalet Bakanı'nın talebine bağlı kılınmasının "yaratacağı sonuca göre, yurt dışında aynı suçu işleyen iki kişiden biri Adalet Bakanı'nın istemi üzerine Türkiye'de yargılanacak, diğeri, istemde bulunulmazsa yargılamadan kurtulabilecektir." değerlendirilmesi yapılmıştır. Böylece bu düzenlemenin sonuç olarak Anayasanın hukuk devleti ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği iddia edilmiştir.

Komisyonumuzda yapılan tartışmalarda, çoğunluk görüşü olarak bu değerlendirmenin doğru olmadığı sonucuna varılmıştır.

⁵⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 958, sh. 1-3.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türk Ceza Kanununun 13'üncü maddesinde sayılan suçlardan dolayı Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için failin Türkiye'de bulunması gerekir.

Türk Ceza Kanununun, vatandaş veya yabancı tarafından yurt dışında işlenen suçtan dolayı Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesinin şartlarının belirlendiği 11 ve 12'nci maddelerinde, bu madde hükümlerinin uygulanabilmesi için yurt dışında işlenen suçun 13'üncü maddede belirlenen suçlardan birinin olmaması gerektiği açıkça vurgulanmıştır.

Türk Ceza Kanununun 13'üncü maddesinde sayılan ve istisna kapsamına alınan suçlardan dolayı Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için bu hususta, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması gerekir. Ayrıca, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, Türkiye'nin barış esasına dayalı diplomatik ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek bir sonuç doğurmaması, Türk milletinin ve bir parçasını oluşturduğu dünya milletler topluluğunun varlığı ve geleceği açısından yararlı olması gerekir.

Türk kamu düzeninin korunmasının ötesinde, uluslararası hukukun yanı sıra, diplomatik ve siyasi bir değerlendirmeyi gerektiren bir yönünün olması dolayısıyla, istisna kapsamında belirtilen suçlardan dolayı Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanının talebine bağlı kılınmasının, eşitsizlik ortaya çıkaracak bir yönü bulunmamaktadır. Kaldı ki Adalet Bakanının bu hususta kullanacağı takdir yetkisi, objektif ölçütlere dayalı olarak kullanılması gereken bir yetkidir. Yurt dışında işlenen suçun, Türk kamu düzenini bozucu bir etkisinin olup olmadığı ve bu suçtan dolayı Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılması hususunda uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüğümüzün bulunup bulunmadığı hususları Cumhuriyet savcıları tarafından hukuki bir değerlendirmeyle tespit edilebilecekken; yapılacak olan soruşturma ve kovuşturmanın Türkiye'nin barış esasına dayalı diplomatik ilişkilerini olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği hususu, diplomatik ve siyasi bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.

Belirtilen nedenlerle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 27.5.2005 tarihli ve 5357 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinde bir değişiklik yapılmasına gerek görülüyerek, maddede aynen kabul edilmiştir.”⁵⁶

TCK'nın 13. maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmesine ilişkin söz konusu çerçeve madde, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek, 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla aynen kabul edilmiştir.

⁵⁶ TBMM Adalet Komisyonunun 24.6.2004 tarihli ve Esas 1/1042, Karar 91 sayılı Raporu (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 958, sh. 10/11).

5377 s. Kanunla 13. maddeye eklenen ikinci fıkranın iptali amacıyla açılmış bulunan iptal davasında Anayasa Mahkemesinin 19 Şubat 2009 tarihli oturumunda vermiş bulunduğu karar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanın ile birlikte 4 Mart 2009 tarihinde mahkeme heyeti önünde bu fıkra hükmünün “kapsam ve uygulama koşulları ile ilgili olarak” sözlü açıklamalarda bulunduk. Mahkeme 5 Mart 2008 tarihli oturumunda, açılan iptal davasının reddine karar vermiştir⁵⁷.

Yeni TCK’nın 13. maddesine göre; kim tarafından, nerede ve hatta, kime karşı işlenmiş olursa olsun; belli suçlardan dolayı Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılabilecektir. Bu madde hükmüyle, belli suçların yurt dışında işlenmesine rağmen, faillerinin Türk vatandaşı veya yabancı olmasına bakılmaksızın, Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılmasına imkan tanınmıştır.

Bu suçlar, madde metninde ve gerekçesinde açık bir şekilde gösterilmiştir:

A- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre, TCK, İkinci Kitap, Birinci Kısım altındaki

- 1) “Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümde,
- 2) “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” başlıklı İkinci Bölümde yer alan suçlar;

B- Söz konusu birinci fıkranın (b) bendine göre, TCK, İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki

- 1) “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlıklı Üçüncü Bölümde,
- 2) “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Bölümde⁵⁸,
- 3) “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci Bölümde,
- 4) “Millî Savunmaya Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölümde,

⁵⁷ RG: 3 Ekim 2009/27365.

⁵⁸ «Sanık, merkezi Roma’da bulunan, amacı Türkiye illerinden Kars, Van, Erzurum ve Trabzon’u içine alan ve tam bağımsız bir Ermeni devleti kurmak (ve ayrıca), 1915 yılında yapıldığını iddia ettiği Ermeni katliamının intikamını almak olan “Lega Armania Dei Dritto Dell Vee” (“İnsan Hakları ermeni Birliği”) isimli derneğin faal üyesidir; bu derneği amacına ulaştırmak için biri Paris’te, diğeri Roma’da Ermenice yayınlanan iki gazetede görev almıştır; bu hususta bir harita düzenleyip bildiri olarak yayınlamıştır; dışarıdaki bu fikirlerini yaymak için Türkiye’ye gelmiştir.

Sanığın, çeşitli faaliyetleri ile Türkiye’nin dört vilayetini de içine alan bağımsız bir ermeni devleti kurmak, dünya kamu oyunu bu yönde oluşturmak, Türkiye’deki soydaşlarını da bu doğrultuda eğitmek şeklinde özetlenebilecek fiil ve hareketlerinin Türkiye Devletinin emniyetine karşı işlenen cürümlerden olmakla, TCK’nın 4. maddesi delaletiyle 142/3. maddesine uyduğu düşünülmenden, 125. maddesinin unsurlarının oluşmadığından bahsedilerek beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.»: 9. CD., 7.7.1978, 2886/3063 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 89).

5) “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” başlıklı Yedinci Bölümde ve
6) “Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar” başlıklı Sekizinci Bölümde
yer alan suçlar;

C- Fıkranın (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan

1) İşkence (m. 94, 95),

2) Çevrenin kasten kirletilmesi (m. 181),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (m. 190),

4) Parada sahtecilik (m. 197), para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçla-
rın üretimi ve ticareti (m. 200), mühürde sahtecilik (m. 202),

5) Fuhuş (m. 227),

6) Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıko-
nulması (m. 223, f. 2, 3) ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme (m. 152)
suçları⁵⁹,

nerede işlenmiş olursa olsun, bu nedenle Türkiye’de yargılama yapılarak,
Türk vatandaşı veya yabancı olmasına bakılmaksızın fail hakkında Türk
kanunlarına göre cezaya hükmolunabilecektir.

Madde metnine göre; yabancı ülkede işlenen bu suçlar dolayısıyla failer hak-
kında Türkiye’de re’sen takibat yapılır.

Bu bakımdan örneğin, işkence fiillerinin cezalandırılabilmesi için, suçun mutla-
ka Türkiye’de gerçekleşmesi, bir Türk vatandaşı tarafından veya bir Türk va-
tandaşına karşı işlenmesi gerekmemektedir. Yeni Türk Ceza Kanunu’na göre,
işkencenin kim tarafından, kime karşı ve nerede yapıldığına bakılmaksızın, fail-
leri Türkiye’de ve Türk kanunlarına istinaden cezalandırılabilir.

Keza, yakın tarihlerde ülkemizde yaşanan kimyasal veya radyoaktif madde atık
ve artıklarıyla dolu varillerin yurt dışından gelen gemilerle sahillerimize bırakıl-
ması ve hatta, bu tür maddelerle yüklü gemilerin karasularımızda kendi hâline
terk edilmesi olayları, toplum olarak çevre kirliliğine karşı duyarlılığımızın art-
masına neden olmuştur. Bu duyarlılığın sonucu olarak, ceza kanununun yer ba-
kımından uygulama alanına ilişkin hükümleri belirlenirken; çevrenin kasten kirle-
tilmesi suçunun kim tarafından ve nerede işlendiğine bakılmaksızın, faillerinin
Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere Türkiye’de yargılanması kabul
edilmiştir. Bu düzenlemelerin yapılmasında, çevre kirliliğine neden olan fiillerin

⁵⁹ *Hafizoğulları*, kapsamına giren suçlar bakımından söz konusu madde metnini eleştirirken,
Türk kanun koyucusunu “işgüzarlık” yapmakla ve ölçüyü kaçırmakla itham etmektedir. Hatta
daha da ileri giderek, söz konusu maddenin “*tamamen faşizan bir zihniyetin ürünü*” olduğunu
iddia etmektedir (HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, sh. 44).

Türkiye'nin egemenlik alanı dışında işlenmesine rağmen, hava sirkülasyonları veya denizlerdeki akıntılarla kirliliğin ülkemize de sirayet etmesi ve özellikle, Türkiye'ye komşu ülkelerdeki eskimiş teknolojilerle çalışan ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik yeterli teknik donanımına sahip bulunmayan nükleer atom enerji santrallerinin halen faaliyette bulunması, büyük ölçüde etkili olmuştur.

27.5.2005 tarihli ve 5357 sayılı Kanunla yeni TCK'nın 13. maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu hükümle, birinci fıkranın (b) bendinde sayılanlar dışındaki diğer suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılmasının ortaya çıkarabileceği siyasi sorunların önüne geçmek amaçlanmıştır. Bu nedenle, maddenin birinci fıkrasında sayılan suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılabilmesi Adalet Bakanının talebine bağlı tutulmuştur.

Maddenin üçüncü fıkrasına göre; *“birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yargılama yapılır.”* Böylece belirlenen kapsama giren suçlar açısından non bis in idem kuralına geçerlilik tanınmamıştır.

Bu bakımdan, örneğin devletin güvenliğine karşı işlenmiş olan suçlar nedeniyle yabancı ülkede hüküm verilmiş ise; Türkiye’de yeniden yargılama yapılabilmesi, Adalet Bakanının talebine bağlıdır (m. 13, f. 3)^{60, 61}. Bu hususta, yabancı ülkede yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün beraat veya mahkûmiyet olması arasında bir fark bulunmamaktadır.

Ancak, yabancı ülkede mahkûm olunan ve infaz edilen cezanın, TCK hükümleri esas alınmak suretiyle Türkiye’deki yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edileceği muhakkaktır⁶².

⁶⁰ Mehmet Ali AĞCA'nın, 11.5.1981 tarihinde Vatikan Meydanında yapılan bir dini tören sırasında PAPA II. Jean PAUL'a suikast düzenlemek suçundan dolayı Roma Ağır Ceza Mahkemesinin 24.9.1981 tarih ve 39/46 sayılı kararı ile müebbeden hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş ve cezası infaz edilmekte iken; aynı suç nedeniyle Türkiye’de yeniden yargılanıp yargılanamayacağı konusunda çıkan uyuşmazlıkla ilgili olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu şu kararı vermiştir:

*«Sanık Mehmet Ali Ağca(’nın) Vatikan Devlet Başkanına karşı (işlediği bu suç, 765 s. mülga) TCK’nın 164. maddesinin uygulanmasını gerektirir (bir suçtur); başka bir deyişle, “Devletin Emniyetine Karşı” (bir suçtur. Bu itibarla,) adı geçen sanığın Türkiye’de yeniden yargılanmasında zorunluluk bulun»*maktadır: CGK., 26.12.1988, 1-325/566 (Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası, sh. 86/87, 94 vd.).

⁶¹ Yurt dışında işlenmiş suçtan dolayı yabancı mahkemece verilmiş bir hükmün varlığı veya yabancı mahkemede yargılama yapılıyor olması, Polonya mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmamaktadır (6 Haziran 1997 tarihli Polonya CK, m. 114, § 1). Ancak, örneğin yabancı mahkemeden verilmiş hükmün Polonya’da infaz edilmesi halinde, yeniden yargılama yoluna gidilmemektedir (Polonya CK, m. 114, § 3).

⁶² Anayasa Mahkemesinin 18.11.2015 tarihli ve 2013/1189 bireysel başvuru sayılı Kararına konu teşkil eden olayda; başvuru hakkında “DHKP/C” terör örgütü üyeliği suçlamasıyla açılan davada Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Alman CK, § 129a hükümlerine istinaden 2 yıl 6 ay hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmeder. Bu cezası kesinleşen

başvurucu, Almanya’da koşullu salıverildikten sonra, 2007 yılında Türkiye’ye gelir ve bunun üzerine hakkında **aynı terör örgütünün yöneticisi** olduğu şüphe ve iddiasıyla Türkiye’de soruşturma ve kovuşturma yapılır.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davada, başvurunun Türkiye’de yargılanabilmesi için TCK, m. 13, f. 3 hükmü uyarınca Adalet Bakanının talebinin sorulmasına karar verilir. Bakanlık yazısında, başvurucuya isnat edilen suça ilişkin düzenlemenin (m. 314) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, Beşinci Bölümünde yer alması nedeniyle, TCK, m. 13, f. 2 uyarınca Adalet Bakanının talebine gerek olmadığı belirtilir. Mahkeme, bunun üzerine yargılamaya devam eder.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, **terör örgütü yöneticisi** olduğunu kabul ederek, başvuru hakkında TCK, m. 314, f. 1 ve Terörle Mücadele Kanunu, m. 5 uyarınca **12 yıl 6 ay hapis cezasına** hükmeder. Mahkeme **aynı suç** sebebiyle başvurunun Almanya’da yargılanarak mahkûm edildiği hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz edilen kısmının TCK, m. 16 uyarınca bu cezadan mahsup edilmesine karar verir. Söz konusu mahkûmiyet hükmü, temyiz incelemesinden geçerek kesinleşir.

Türk vatandaşı olan başvuru hakkında, 1994 yılında Almanya’ya gitmeden önce işlediği herhangi bir suçtan dolayı soruşturma başlatıldığına dair bilgi mevcut değildir.

Başvuru Almanya’da kaldığı süre zarfında örgüte zorla para toplamaktan dolayı daha önce hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmuş ve fakat bu cezanın infazı ertelenmiştir. Mensubu olduğu ve bünyesinde çeşitli “görev”ler ifa ettiği örgütün faaliyeti çerçevesinde çeşitli ülkelere seyahatler gerçekleştirmiş olan başvuru, örgütsel faaliyetleri sebebiyle Almanya, Fransa ve Hollanda’da tutuklanmıştır.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuru terör örgütü yöneticiliği suçundan dolayı mahkûm ederken, gerekçe olarak, başvurunun yurt dışında çeşitli ülkelerdeki faaliyetlerini göz önünde bulundurmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, başvurunun 2003 yılında iki defa Türkiye’ye silah ve mermi gönderdiği bilgisine yer verilmiştir; ancak karar metninde bu iddia ile ilgili başka herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Keza, yargılama sırasında dinlenen tanıklardan biri, başvurunun örgüt içinde sorumlu düzeyde olduğunu, “*Türkiye’de düzenlenen bombalı saldırıların talimatını verdiğini, devlet büyüklerine suikast düşüncesi içinde olduğunu söylediğini belirtmiştir*”; ancak, karar metninde söz konusu talimatın hangi bombalı saldırı veya saldırılar ile ilgili olduğuna dair somut bir bilgiye yer verilmemiştir. Mahkemece başvuru hakkında terör örgütü yöneticiliği suçundan mahkûmiyet hükmü kurulur iken, delil olarak bu bilgilere itibar edilmiş ise de (Paragraf no. 23), herhangi bir kişiyi öldürmeye veya yaralamaya azmettirmeden dolayı hakkında hüküm kurulmamıştır.

TCK, m. 314’de tanımlanan “Silahlı örgüt” üyeliği ve yöneticiliği suçları yabancı bir ülkede işlense bile, faili, vatandaş veya yabancı olmasına bakılmaksızın, Türkiye’de resen yargılanır ve Türk kanunlarına göre cezalandırılır (TCK, m. 13, f. 2). Yurt dışında işlenen bu suçlardan dolayı yabancı ülkede yargılama yapıp, faili hakkında mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Türkiye’de bulunması koşuluyla ve Adalet Bakanının talebine bağlı olarak yeniden yargılama yapılabilir (TCK, m. 13, f. 3).

Karara konu teşkil eden olayda, başvuru, Alman mahkemesi tarafından yurt dışında işlediği kabul edilen fiillerin terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmiş ve bu ceza Almanya’da infaz edilmiş olmasına rağmen, aynı fiiller sebebiyle Türkiye’de yeniden yargılanırken, Adalet Bakanının talebi istihsal edilmemiştir. Söz konusu fiiller dolayısıyla Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için Adalet Bakanının talebine gerek bulunmadığı yönündeki Bakanlık yazısı, bu fiillerden dolayı Türkiye’de yeniden yargılama yapılabilmesi için talep koşulunu karşılamamaktadır. Buna rağmen ilk derece mahkemesi yargılamaya devam ederek başvuru hakkında cezaya hükmetmiştir.

Keza belirtmek gerekir ki; Türkiye'nin taraf olduğu pek çok anlaşmada *aut dedere aut punire* kuralına yer verilmiştir. Bu kuralın yer aldığı anlaşmalarla, belli suçların; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine veya anayasal düzenine karşı ya da Türkiye'nin zararına olarak işlenmiş suç olmamasına, fail ve mağdurlarının Türk vatandaşı olmamasına ve ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alanı dışında işlenmiş olmasına rağmen; Türkiye'ye yargılama yapma konusunda yükümlülük tahmil edilmektedir⁶³.

Ancak Anayasa Mahkemesine göre, başvuru hakkında Alman mahkemesi tarafından sadece Ocak 1997 ile Ekim 1998 yılları arasında Almanya'da işlediği kabul edilen fiiller dolayısıyla mahkûmiyet hükmü kurulmuştur; başvurunun Belçika ve Hollanda'da örgüt yöneticiliği bağlamında icra ettiği fiiller yargılama konusu yapılmamıştır ve dolayısıyla, bu fiiller bakımından yeniden yargılama söz konusu değildir. Başka bir ifadeyle, Anayasa Mahkemesince, söz konusu olayda aynı fiiller sebebiyle tekrar yargılama değil, farklı fiiller sebebiyle yargılamanın olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenledir ki, başvuru hakkında Türkiye'de hükümlenen cezadan Almanya'da hükümlenen cezanın infaz kurumunda çekilen kısmının mahsup edilmesi de Anayasa Mahkemesince hukuki dayanaktan yoksun bulunmuştur (Paragraf no. 7, 45).

Dikkat edilmelidir ki, gerek örgüt yöneticiliği gerek örgüt üyeliği suçları kesintisiz, mütemadi suçlardır. Kişinin örgüt yöneticisi veya üyesi olarak sorumlu tutulduğu zaman zarfında işlediği fiillerin bir kısmının değerlendirme konusu yapılmadığı gerekçesiyle, değerlendirme dışı bırakılan fiiller göz önünde bulundurularak bu kişi hakkında tekrar örgüt yöneticisi veya üyesi olmaktan dolayı sorumluluk yoluna gidilemez. Kaldı ki, Alman mahkemesi başvuru hakkında terör örgütü üyeliği suçundan dolayı mahkûmiyet kararı kurarken, sadece Ocak 1997 ile Ekim 1998 yılları arasında işlediği fiillere dayanmamıştır (Paragraf no. 9). Keza, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuru hakkında mahkûmiyet hükmü kurarken, Almanya'da açılan ve karara bağlanan dava dosyası içeriğini ve Alman mahkemesinin kararını delil olarak değerlendirmiştir (Paragraf no. 22).

Tekrar yargılama bağlamında teknik suç tanımlarını değil, suç oluşturan fiilleri göz önünde bulundurmak gerekir. Her ne kadar Almanya'da terör örgütü üyeliği suçundan mahkûm olan başvuru, Türkiye'de terör örgütü yöneticiliği suçundan mahkûm edilmiş ise de, bu suçlardan dolayı mahkûmiyet hükmünün kurulmasında **aynı fiiller** dikkate alınmıştır. Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin kabulünün aksine, Almanya'da terör örgütü üyeliği suçundan mahkûm edilen başvuru, aynı fiillere istinaden Türkiye'de terör örgütü yöneticisi olarak mahkûm edildiği davada, **tekrar yargılanmıştır**. Ancak, milletlerarası ceza hukukunda geçerli koruma prensibinin gereği olarak "non bis in idem" kuralına getirilen bir istisna (TCK, m. 13, f. 3) çerçevesinde yapılan bu ikinci yargılama ve verilen hükümle, başvuru bakımından bir hak ihlali bulunulmuş değildir.

Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin mahsupla ilgili değerlendirmesi de sorunludur.

Bu kararlar da göstermektedir ki, aynı fiiller dolayısıyla Türk kanunlarına göre verilen cezalar ile yabancı ülke kanunlarına göre verilen cezalar arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Bu farklılığın **ölçülülük** çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir.

⁶³ 1963 yılında imzalanan *Uçaklara Karşı İşlenen Suçlara veya Diğer Fiillere İlişkin Tokyo Sözleşmesine* göre (m. 16); bu Sözleşme kapsamına giren suçlar hakkında suçun işlendiği yerde koğuşurma yapılmaktan vazgeçilirse, fail, uçağın sicilne kayıtlı olduğu devlete iade edilebilecektir (Türkiye, bu Sözleşmeyi 17.04.1975 t. ve 1889 s. Kanuna dayanarak onaylamış olup; Sözleşme metni, 8.12.1975 t. ve 15436 s. Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

1970 yılında imzalanan *Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi hakkındaki La Haye Sözleşmesinin* 1. maddesinde haksız olarak ve cebir ya da tehdit ile uçuş halindeki bir uçağı ele geçirme veya kontrolüne sahip olma suç sayılmıştır. Sözleşmenin 8. maddesinin 1. fıkrasına göre uçak kaçırma suçu iade edilebilir bir suç olarak kabul edilecektir (Tür-

kiye, bu Sözleşmeyi 30.11.1972 t. ve 1634 s. Kanuna dayanarak onaylamış olup; Sözleşme metni, 31.3.1973 t. ve 14493 s. Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

Sözleşmenin 7. maddesine göre; Sözleşme kapsamına giren bir suç işlediği sanılan kişi (ler)in, ülkesinde bulunduğu devlet tarafından iade edilmemeleri durumunda, suç kendi ülkesinde işlensin veya işlenmesin yargılanması yükümlülüğünü getirmektedir.

Yine 23 Eylül 1971 tarihli *Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi*nin 1. maddesinde uçahta bulunan kimseler üzerinde uçağın güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde cebir ve şiddet kullanılması, uçağın tahrip edilmesi, uçuş güvenliği için tehlikeli olan bilgiler verilmesi, bütün bu eylemlere teşebbüs ve iştirak edilmesi bir suç olarak nitelendirilmiştir. Montreal Sözleşmesi'nde iade hukukuna ilişkin hükümleri içeren 7 ve 8. maddeler, La Haye Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin bir tekrarı niteliğindedir (Türkiye, bu Sözleşmeyi 17.04.1975 t. ve 1888 s. Kanuna dayanarak onaylamış olup; Sözleşme metni, 29.11.1975 t. ve 15427 s. Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

Birleşmiş Milletler tarafından 14 Aralık 1973 tarihinde *Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair New York Sözleşmesi* hazırlanıp devletlerin onayına sunulmuştur (Türkiye, bu Sözleşmeyi 21.1.1981 t. ve 2374 s. Kanuna dayanarak onaylamış olup; Sözleşme metni, 1.5.1981 t. ve 17327 s. Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

Sözleşme kapsamına giren ve “*Uluslararası Korunmaya Sahip Kimseler*”e karşı işlenen suçların (m. 2) faillerinin cezasız kalmaması için, ülkesinde bulunduğu devlet tarafından iade edilmediği takdirde yargılanmalarının sağlanması amacıyla olayın en kısa zamanda yetkili yargı organlarına intikal ettirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır (m. 7).

Avrupa Konseyi'nce 27.01.1977 tarihinde hazırlanan *Tedhişçiliğin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi* tedhişçiliğin önlenmesi konusunda günümüz açısından son uluslararası belge niteliğindedir. Bu Sözleşmeye göre (m. 6, 7); taraf devletler, Sözleşme kapsamına giren suçlar (m. 1, 2) nedeniyle iadesi istenen bir kimseyi iade etmedikleri takdirde, kendisi yargılamaya yapacaktır (Türkiye, bu Sözleşmeyi 27.10.1980 t. ve 2327 s. Kanuna dayanarak onaylamış olup; Sözleşme metni, 26.3.1981 t. ve 17291 s. Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

Türkiye'nin de taraf olduğu *Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi*nin “*Cezaî Hükümler*” başlığını taşıyan 36. maddenin 1. fıkrasında taraf devletlerin kendi yasal düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla “*uyuşturucu maddelerin işbu sözleşme hükümlerine uygun olmayan bir şekilde yapılacak ekim ve istihsalinin, imalinin, istihracının, hazırlanmasının, elde bulundurulmasının, arzının, satışa arzının, dağılımının, satın alınmasının, satışının, herhangi bir maksatla tesliminin, simsarlığının, gönderilmesinin, transit olarak sevkinin, naklinin, ithal ve ihracının veya sözü geçen tarafın görüşüne nazaran, işbu sözleşme hükümlerine aykırı olabilecek her türlü fiillerin kasten yapılmasının*” suç telâkki edileceği belirtilmiştir. Yine aynı bu maddenin 2. fıkrasının a bendinin ii kısmında, 1. fıkrada sayılan “*suçlardan herhangi birine kasten katılmak, suça ika maksadıyla birleşmek veya anlaşmak veya ikaina teşebbüs etmek ve işbu maddede bahis konusu suçlarlar ilgili olarak kasten yapılan hazırlık fiilleri ile malî muameleler*” de suç sayılacaktır.

2. fıkranın b bendinde “*1. fıkra ve 2. fıkranın a bendinin ii kısmında bahsedilen suçların, taraflar arasında imzalanmış veya imzalanacak olan suçluların geri verilmesi anlaşması hükümlerine göre geri vermeyi gerektiren birer vaka addolunması ve suçluların geri verilmesini bir anlaşmaya veya mütekabiliyete bağlamaya tarafların kendi aralarında geri verme hali olarak kabul olunması arzuya şayandır; şu kadar ki, geri verme, kendisine geri verme talebi yapılan tarafın mevzuatı uyarınca uygulanacak ve sözü geçen taraf yetkili makamları suçu yeter derecede ağır saymadıkları takdirde, suçlunun tevkifini veya geri verilmesini red hakkını haiz olacaklardır*” denilmektedir. Yine 1. fıkranın a bendinin iv kısmında “*Yukarıda sözü edilen ağır suçlar, bunları ika edenler vatandaş veya yabancı olsun, suçun ülkesi üzerinde işlendiği tarafça, veya iade talebinin vaki olduğu tarafın mevzuatı gereğince suçlunun geri verilmesi şayanı kabul değilse ve söz konusu suçlu önceden takip ve muhakeme edilmemişse suçlunun ülkesi üzerinde bulunduğu tarafça takip olunacaktır*” denilerek aut dedere, aut punire

Meselâ, milletlerarası sahada tedhiş fiillerinin “siyasi suç” sayılmaması konusunda görüş birliği sağlanamadığından; bu fiiller dolayısıyla 1960’lı yıllarda “*aut dedere, aut punire*” (“cezalandır veya iade et”) (daha doğru bir deyimle, “*aut dedere, aut judicare*” [“yargıla veya iade et”])⁶⁴ kuralı ortaya atılmış ve gün geçtikçe de uluslararası metinlerde yer almaya başlamıştır. Bu kuralın yer aldığı örneğin 27.01.1977 tarihli “*Tedhişçiliğin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi*”ne göre; taraf devletler, tedhiş fiillerini “siyasi suç” kabul ederek, faillerini ilgili devlete iade etmekten imtina etse bile; bu fiiller nedeniyle yargılamakla ve faillerini cezalandırmakla yükümlü olacaktır⁶⁵.

Vatandaşın TCK’nın 13. maddesi kapsamına giren bir suçu yurt dışında işlemesi halinde, Türk kanunlarına istinaden cezalandırılabilmesi için hakkında yargılama TCK’nın 11. maddesi hükümlerine göre değil, yine 13. madde hükümlerine göre yapılacaktır. Buna göre, vatandaş, örneğin yurt dışında bir yabancıya karşı işlediği kasten öldürme suçundan dolayı, TCK’nın 11. maddesindeki şartların varlığı halinde, Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere Türkiye’de hakkında re’sen kamu davası açılabilir ve yargılanabilecektir. Buna karşılık, örneğin vatandaş tarafından yurt dışında işlenmiş olan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi, 11. madde hükümlerine göre değil, 13. madde hükümlerine göre mümkün olabilecektir. Vatandaşın uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi yurt dışında imal etmesi, yurt dışında satın alması ve yurt dışında satması durumlarında, fiil Türkiye’de işlenmiş değildir. 5377 sayılı Kanunla 13. maddeye eklenen ikinci fıkra hükmü gereğince, bu suçtan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için Adalet Bakanının talepte bulunması gerekmektedir⁶⁶. Ancak, göz önünde bulundurulmalıdır ki, 13. maddenin birinci fıkrasının (c) ve müteakip bentlerinin çoğunda yer alan suçlar dolayısıyla Türkiye’nin yargılama yetkisi, **tali bir yetkidir**. Başka bir deyişle, Türkiye’nin taraf olduğu pek çok milletlerarası sözleşmede, belirli suçlarla ilgili olarak “**ya iade et ya da yargıla ve cezalandır**” kuralı kabul edilmiştir. Söz konusu bentler kapsamına giren suçlar dolayısıyla yargılamanın en sağlıklı bir şekilde yapılabileceği

kuralına yer verilmiştir (Türkiye, bu Sözleşmeyi 27.12.1966 t. ve 812 s. Kanuna dayanarak onaylamış olup; Sözleşme metni, 12.5.1967 t. ve 12596 s. Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

21.12.1971 tarihinde Viyana’da *Psikotrop Maddeler Sözleşmesi* imzalanmıştır. Bu Sözleşme de, kapsamına giren (m. 22) suçlarla ilgili olarak iade ve yargılama konusunda yukarıda sözü edilen TEK Sözleşmesi hükümlerini tekrarlamıştır (Türkiye, bu Sözleşmeyi 27.10.1980 t. ve 2326 s. Kanuna dayanarak onaylamış olup; Sözleşme metni, 7.3.1981 t. ve 17272 s. Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

⁶⁴ ALPASLAN, M. Şükrü: *Kriminoloji ve Hukuk Açısından Tedhişçilik*, İstanbul, 1983, sh. 250.

⁶⁵ BAYRAKTAR, Köksal: *Siyasal Suç*, İstanbul, 1982, sh. 201; ALPASLAN, sh. 251.

⁶⁶ Nitekim Yargıtay, vatandaş tarafından yurt dışında işlenmiş olan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için, “*Adalet Bakanlığından görüş sorulması gerektiği*” yönünde içtihatla bulunmuştur: 10. CD, 11.12.2007, 16011/14576 (Metiner, Haydar/Koç, E. Ahsen: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Genel Hükümleri, Cilt I, Ankara Mart 2008, sh. 242).

yer, suçun işlendiği yerdir. Şayet kişi suçu işlediği ülke devletine iade edilemiyorsa, Türk kanunlarına göre cezalandırılmak üzere Türkiye’de yargılanabilecektir. Bu itibarla, gerivermenin mümkün olduğu hallerde, yurt dışında işlenen suç 13. maddenin birinci fıkrasının (c) ve müteakip bentlerinin çoğunda yer alan suçlardan olsa bile, faili Türkiye’de yargılanamayacak ve suçun işlendiği ülkeye iade edilecektir. Buna karşılık, örneğin vatandaş tarafından yurt dışında işlenmiş olan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı kişinin vatandaş olması sebebiyle suçun işlendiği ülkeye iade mümkün olmadığı için, Türkiye’de yargılama yapılacaktır. Ancak, bu suçtan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için, Adalet Bakanının talepte bulunması gerekmektedir^{67,68}.

Keza belirtilmelidir ki, bu çerçevede Adalet Bakanının talebi, belli bir suçla ilgili olarak **yargılama** yapılabilmesi bakımından şart olarak aranmaktadır. Yargılama, kovuşturma evresinde yürütülen bir faaliyettir. Bu itibarla, yeni TCK’nın düzenlemesinde “talep”, bir soruşturma şartı olarak değil, **sadece bir kovuşturma şartı** olarak öngörülmüştür. Başka bir deyişle, Adalet Bakanının talebinin şart olarak arandığı durumlarda Cumhuriyet savcıları re’sen soruşturma işlemlerini başlatabilirler. 13. madde kapsamında değerlendirilebilecek somut olayda kamu davasının açılmasına yetecek delillerin varlığı halinde, iddia-name düzenlenmeden önce Adalet Bakanının talebinin alınması gerekmektedir.

İzin gibi talep de suçla ilgili bir kovuşturma şartıdır. Bu nedenle, bir suçla ilgili olarak bulunan talep, bütün suç ortakları hakkında kovuşturma yapılmasına imkân verir.

⁶⁷ Yargıtay, Adalet Bakanlığının talebine rağmen, vatandaşın yurt dışında işlediği uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan suçtan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için, aynı fiil sebebiyle yabancı bir devlet mahkemesinden hüküm verilmemiş olmasını şart olarak aramaktadır:

Yargıtay 10.Ceza Dairesi’nin 27.11.2014 tarihli ve E. 2014/3280, K. 2014/13148 sayılı Kararına konu teşkil eden olayda, sanıklara isnat olunan suç, "yurt dışında uyuşturucu madde ticareti yapma" suçudur. Bu suç nedeniyle sanık H, Avusturya Mahkemesi tarafından ... 10 yıl ağır hapis cezasına, sanık A, Romanya Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına, sanık N ise, yine Romanya Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına mahkûm edilir ve hükümlerin kesinleşir.

Bu olayda sanıkların Türkiye’de yeniden yargılanmaları ile ilgili olarak şu karara varılmıştır: TCK’nın 13. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, yurt dışında işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi için yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması gerekir; hüküm verilmiş ise aynı suçtan dolayı Türkiye’de yeniden kovuşturma yapılamayacaktır. Böylece yabancı ülkede hüküm verilmesi halinde, aynı fiilden dolayı birden fazla hüküm verilemeyeceğine ilişkin "non bis in idem" kuralının kabul edildiği gözetilmeden; TCK’nın 13. maddesi ile CMK’nın 223. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca sanıklar hakkındaki davaların reddine karar verilmesi gerekirken, sanıkların mahkûmiyetlerine hükmolunması, ... kanuna aykırı bulunmuştur.

⁶⁸ Soykırım, insanlığa karşı diğer suçlar ve savaş suçları gibi suçlar dolayısıyla, nerede, kim tarafından ve kime karşı işlendiğine bakılmaksızın, faillerinin Alman kanunlarına göre cezalandırılmak üzere yargılanabilmeleri için, Almanya’da bulunmaları şart değildir. Ancak, Alman CMK’nın 153f paragrafında bu suçların Almanya dışında işlenmesi, fail ve mağdurunun Alman vatandaşı olmaması ve Almanya’da ikamet etmemesi halinde savcılara kamu davasını açma hususunda takdir yetkisi tanınmıştır.

Buna karşılık, zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği hallerde, bu kapsamda mütalaa edilen her bir suç için talep koşulunun ayrıca gerçekleşmesi gerekir.

Bazı ceza kanunlarında evrensellik ilkesi gereğince hangi suçlar dolayısıyla yargılama yapılacağı sayma yöntemiyle belirlenmemiş olup, ilgili milletlerarası sözleşmelere yollamada bulunulmuştur⁶⁹. Bazı ceza kanunlarında ise, evrensellik ilkesi bağlamında devletin yargılama yetkisinde bulunduğu suçlar tek tek sayılmıştır⁷⁰.

Belirtmek gerekir ki, TCK'nın 13. maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı Türkiye'de yargılama yapılabilmesi için, TCK'nın 19. maddesinin birinci fıkrası

⁶⁹ Örneğin 5.6.1996 tarihli Rusya Federasyonu CK, m. 12, f. 3; 21 Kasım 1937 tarihli İsviçre CK, m. 6 bis 5; 6 Haziran 1997 tarihli Polonya CK, m. 113.

⁷⁰ Örneğin Alman CK, § 6; Avusturya CK, § 64, f. 1.

Bazı kanunlarda birtakım suçlar bir milletlerarası anlaşmaya dayanmamasına rağmen evrensellik ilkesi kapsamında değerlendirilmiştir. **Kitle imha silahlarının imali ve dağıtımı** suçu, buna örnek gösterilebilir (Avusturya CK, § 64, f. 1; Alman CK, § 6, f. 1, bent 2). Alman CK'da, **müstehten içerik taşıyan ürünlerin dağıtılması** (§ 6, bent 6), **sübvansiyon dolandırıcılığı** (§6, bent 8) gibi suçlar evrensellik ilkesi kapsamında değerlendirilerek, nerede, kim tarafından ve kime karşı işlendiğine bakılmaksızın, failleri Alman kanunlarına göre cezalandırılmak üzere Almanya'da yargılanabilecektir.

Alman CK'da **soykırım** suçu önce evrensellik ilkesi kapsamında mütalaa edilmişken, bilahare 26 Haziran 2002 tarihli "**Devletlerarası Ceza Kanununun Yürürlük Kanunu**" ("*Gesetz zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches*") adlı Kanunla bu kapsamdan çıkarılmış (§ 6, bent 1) ve Alman CK'nın soykırım suçunu düzenleyen 220. paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. Soykırım suçu, söz konusu "**Devletlerarası Ceza Kanunu**" kapsamına alınarak yeniden tanımlanmıştır (Artikel 1, § 6).

Söz konusu Kanunda soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları yeniden tanımlanarak, nerede, kim tarafından ve kime karşı işlendiğine bakılmaksızın bu suçlardan dolayı Alman kanunları uygulanmak suretiyle cezalandırma yoluna gidilebilmesi ve bu suretle Milletlerarası Ceza Mahkemesinin görevinin Alman hukuku bakımından tali (ikincil ve tamamlayıcı) bir görev (Milletlerarası Ceza Mahkemesinin Statüsünü belirleyen 1998 tarihli Roma Statüsü, m. 17) olması sağlanmıştır.

Söz konusu Kanunun "**Devletlerarası Ceza Kanunu**" ("*Völkerstrafgesetzbuch*") başlığını taşıyan Birinci Kitabının (Artikel 1) beş paragraftan oluşan Birinci Bölümünde genel hükümlere yer verilmiştir. Birinci paragrafa göre, yurt dışında işlenmiş olan soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları ile ilgili olarak, Almanya ile herhangi bir bağlantısı bulunması bile, bu Kanun hükümleri uygulanacaktır. Yani nerede, kim tarafından ve kime karşı işlendiğine bakılmaksızın bu suçlardan dolayı Alman kanunları uygulanmak suretiyle faillerin cezalandırılması yoluna gidilebilecektir. İkinci paragrafa göre, bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla genel ceza hukuku ilkeleri, birinci, üçüncü dördüncü ve beşinci paragraflarda özel hüküm bulunmaması halinde uygulama kabiliyeti bulacaktır. Üçüncü paragrafta kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep olarak hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi düzenlenmiştir. Dördüncü paragrafa göre, askeri hiyerarşide üst, sivil hiyerarşide amir konumundaki kişilerin bu Kanunda tanımlanan suçların ast veya emredilenler tarafından işlenmesini engellemeleri halinde, ast veya emredilenin işlediği suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulacaklardır. Bu durumda suçun ihmali davranışla işlendiğinden bahisle cezada indirim yapılmaz. Beşinci paragrafta, bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla dava ve ceza zamanasımının işlemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

İkinci Bölüm altında yer alan Birinci Alt Bölümde **soykırım** (§6) ve **insanlığa karşı suçlar** (§7), İkinci Alt Bölümde **savaş suçları** (§8-12), Üçüncü Alt Bölümde ise, "diğer suçlar" başlığı altında gözetim yükümlülüğünün ihlali (§13) ve bu Kanun kapsamına giren suçların bildirilmemesi (§14).

sı hükmü karşısında, fiilin işlendiği ülke devleti kanunlarına göre de suç oluş-
turması gerekmektedir^{71,72}.

**TCK'nın 13. maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı Türkiye'de yargıla-
ma yapılabilmesi için, failin Türkiye'de bulunması şarttır.** Aksi takdirde kişi
hakkında Türkiye'de soruşturma başlatılsa bile savunması alınamayacağı için hak-
kında kamu davası açılmayacak, açılmış olan kamu davasına devam edilerek hak-
kında hüküm kurulamayacaktır. Nitekim, söz konusu 13. maddeye ikinci fıkra ola-
rak eklenen hükmün kabul edildiği 5357 sayılı Kanun Cumhurbaşkanlığı makamın-
ca yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildikten sonra,
TBMM Adalet Komisyonunda yapılan müzakereler sonucunda hükmün aynen ka-
bulüne yönelik olarak verilen kararın gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

*“Türk Ceza Kanununun 13'üncü maddesinde sayılan suçlardan dolayı
Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için failin Türkiye'de
bulunması gerekir.”⁷³*

D. Yurt Dışında Verilmiş Olan Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları

Bu konuda yeni TCK'nın 17. maddesinde düzenleme yapılmıştır:

*“Yukarıdaki maddelerde açıklanan hâllerde mahkeme, yabancı mahke-
melerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyen hükmün, Türk
kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmesi hâlinde, Cumhuri-
yet savcısının istemi üzerine Türk kanunlarındaki sonuçlarının geçerli
olmasına karar verir.”⁷⁴*

Bu hükmün gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir⁷⁵:

*“Hükûmet Tasarısının 16'ncı maddesinde yabancı ülkede verilmiş
mahkûmiyet kararına bağlı hak yoksunluklarının Türkiye'deki etkisi dü-*

⁷¹ Alman hukukuna göre evrensellik ilkesi gereğince Almanya'da yargılama yapılabilmesi için, Alman kanunlarına göre suç oluşturan fiilin işlendiği ülke kanunlarına göre suç oluşturup oluşturumaması **önem taşımamaktadır** (Alman CK, § 6; Alman “Devletlerarası CK”, § 6 vd.). Fransız CK, sadece cünhalar bakımından fiilin işlendiği ülke kanunlarına göre de suç oluş-
turmasını bir şart olarak aramaktadır (22 Temmuz 1992 tarihli Fransız CK, m. 113-6, f. 2).

Buna karşılık kanunların çoğuna göre, fiilin işlendiği ülke kanunlarına göre de suç oluşturma-
sı gerekmektedir (21 Kasım 1937 tarihli İsviçre CK, m. 6 bis 5; 5 Haziran 1996 tarihli Rusya
Federasyonu CK, m. 12, f. 1; 6 Haziran 1997 tarihli Polonya CK, m. 111, § 1).

⁷² *Bakıcı'nın*, madde metnine yönelik eleştirilerini (BAKICI, Ceza Hukuku Genel Hükümleri, sh. 238 vd.) doğru bulmuyoruz.

⁷³ TBMM Adalet Komisyonunun 24.6.2004 tarihli ve Esas 1/1042, Karar 91 sayılı Raporu (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 958, sh. 10/11).

⁷⁴ *Özbek*, bu düzenlemeyi non bis in idem kuralı ile “çelişir nitelikte” (?) görmektedir: ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 3. bası, sh. 251.

⁷⁵ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 418.

zenlenmiştir. Yürürlükteki kanunun 8. maddesinin tekrarı olan bu hüküm, düzenlemesi itibarıyla adalet esasına göre uygulanabilirliği olan bir hüküm değildir. Gerçekten yabancı bir mahkeme tarafından hükmolunmuş olan cezaya, bu kararın verildiği ülke hukukunda bağlanmış olan hak yoksunluklarını esas alan düzenlemeler, sağlıklı bir sonuç vermekten uzaktır. Özellikle her ülkedeki mahkûmiyete bağlı hak yoksunluklarının kapsamının farklı olması çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Nitekim bazı ülkelerde hak yoksunluklarına ayrıca hükmedilmediğinden, bunlar mahkeme kararında belirtilmezler. Bu durum da göstermektedir ki, hak yoksunlukları bakımından yabancı ülke hukukunun esas alınması ülke içinde yeknesak ve adil bir uygulamaya imkan vermemektedir. İşte bu nedenlerdir ki, madde metninde, eşitlik ilkesi gereği olarak, yabancı bir mahkeme tarafından hükmedilmiş olan cezaların, doğurduğu hak yoksunlukları bakımından ülkemiz hukukunun dikkate alınması kabul edilmiştir.”

5352 sayılı **Adli Sicil Kanununun** “Adli sicil kayıtlarının tutulması” başlıklı 2'nci maddesine göre, Türk vatandaşları “hakkında ... yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet karar”ları da adli sicile kaydedilmektedir.

Söz konusu Kanunun “Adli sicile kaydedilecek bilgiler” başlıklı 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin gereği olarak; “Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,” adli sicile kaydedilir.

Yeni TCK'nın 17'nci maddesi hükmüne göre, yabancı mahkemeler tarafından Türk vatandaşları ile ilgili olarak verilmiş mahkûmiyet kararlarına, Türk hukukunda bağlanan hukuki sonuçları belirlemek amacıyla mahkemece karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Türk vatandaşları ile ilgili olarak yabancı mahkemelerden verilen mahkûmiyet kararlarına Türk hukukuna göre bağlanan sonuçların belirlenmesine yönelik olarak Türk mahkemelerince verilen kararlar adli sicile kaydedilecektir⁷⁶.

Buna karşılık; Kanunun “Adli sicil bilgilerinin silinmesi” başlıklı 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre;

“Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adli sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adli sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alı-

⁷⁶ TBMM Adalet Komisyonunun 11.5.2005 tarihli ve Esas 2/444, Karar 78 sayılı Raporu (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 899).

nır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.”

III. Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanına İlişkin Kuralların Kabahatler Bakımından Uygulanması

5326 s. Kabahatler Kanununun “Yer bakımından uygulama” başlıklı 6. maddesine göre;

“5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya ilişkin 8'inci maddesi hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm bulunan haller saklıdır.”

Bu hükmün gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir⁷⁷:

“Madde metninde, kabahatler açısından yer bakımından uygulama ile ilgili olarak yeni Türk Ceza Kanununun 8'inci maddesi hükmüne atıfta bulunulmuştur. Böylece, bu Tasarı hükümlerinin kural olarak ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alanında işlenen kabahatler açısından uygulanabileceği kabul edilmiştir. Buna karşılık, istisna olarak, ilgili kanunda belli bir kabahatin yurt dışında işlenmesi halinde dahi Türkiye'de idari yaptırım uygulanabileceğine dair hüküm bulunabilir.”

⁷⁷ Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 840.

§29. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması

Faili ister Türk vatandaşı ister yabancı olsun, yabancı ülkede işlenen suç dolayısıyla Türkiye’de yargılama yapma imkanının bulunduğu durumlarda, **olaya ancak Türk kanunları uygulanabilir**. Ancak bu uygulama sırasında suçun işlendiği ülke devleti kanunlarının gözönünde bulundurulması gerekebilir.

Bu itibarla, ceza hukuku alanında Türk hakimi yargılamak mevkiinde olduğu somut olayla ilgili olarak **ancak Türk kanunlarını uygulamak** görev ve yetkisine sahiptir. Ancak, bu uygulama yapılırken, yabancı kanunun gözönünde bulundurulması mümkündür⁷⁸. Örneğin vatandaşın yurt dışında işlediği ve mağduru yabancı olan bir suç sebebiyle Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılanıp cezalandırılabilmesi için, Türk kanunlarına göre suç oluşturan fiilin, işlendiği ülke devleti kanunlarına göre de suç oluşturmaya gerekir⁷⁹. Bu bağlamda, ceza hukuku uygulamasında **yabancı kanunun göz önünde bulundurulmasından** söz edebiliriz.

Yeni TCK’nın 19. maddesinde Türk hakimi tarafından ceza hukuku uygulamasında yabancı kanunun hangi hallerde ve ne suretle göz önünde bulundurulabileceğine dair düzenleme yapılmıştır:

“Türkiye’nin egemenlik alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye’de yargılama yapılırken, Türk kanununa göre verilecek olan ceza, suçun işlendiği ülke kanununda öngörülen cezanın üst sınırından fazla olamaz.” (f. 1)

“Ancak suçun;

a) Türkiye’nin güvenliğine karşı veya zararına olarak,

b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi zararına olarak,

İşlenmesi durumunda, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.” (f. 2)⁸⁰

Bu maddenin **gerekçesinde** şu açıklamalara yer verilmiştir⁸¹:

“Türk hâkimi, yargılamak durumunda olduğu somut olayla ilgili olarak ancak Türk kanunlarını uygulamak görev ve yetkisine sahiptir. Bu nedenle, yabancı kanunun doğrudan doğruya yurt içinde uygulanması kabul edilemez.

⁷⁸ Bu konuda, özellikle mülga 765 sayılı TCK’daki düzenlemeye, bu düzenlemenin kanunlaşma sürecine, bu düzenleme ile ilgili Yargıtay uygulamasındaki ve doktriner görüşlerdeki çarpıklıklara ilişkin ayrıntılı bilgi için Kitabımızın 11. ve önceki basılarına bakılabilir (11. bası, sh. 941 vd).

⁷⁹ Bkz. TCK, m. 11 gerekçesi.

⁸⁰ *Özbek*, bu düzenlemeyi “son derece yerinde” bulmaktadır: ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 3. bası, sh. 263 vd. Ancak, doktrinde bazı yazarlar, Hükümet Tasarısındaki düzenlemenin “daha yerinde bir düzenleme”(?) olduğunu savunmaktadırlar (YARSUVAT/BAYRAKTAR ve diğerleri, sh. 293).

⁸¹ TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 420 vd.

Aksi görüş, Devletin hâkimiyet ilkesiyle bağdaşmadığı ve Anayasaya aykırı olduğu gibi, uygulamada da pek çok güçlüğe ve hatta imkansızlığa sebep olur. Çünkü, yabancı ceza kanununun uygulanması, hem fiilin suç olarak tespitinde ve cezanın tayininde yabancı kanunun ölçü olarak alınması anlamına gelmektedir. Türk hâkiminin yabancı kanunu bu şekilde uygulama yükümlülüğü, yukarıda da değinildiği üzere, egemenlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, böyle bir yükümlülüğün tam anlamıyla yerine getirilebilmesi de olanaklı değildir. Buna karşılık, adalet ilkesi gereğince yabancı kanunun göz önünde tutulması mümkündür. Nitekim madde metninde yabancı kanunun göz önünde bulundurulması hususunda bir hükme yer verilmiştir.

*Bu düzenlemeyle öngörülen uygulama şöyle olacaktır: Türk hâkimi yargılamakta olduğu olayla ilgili olarak **fail hakkında önce Türk kanunlarına göre bir ceza belirleyecektir.** Ancak, Türk kanununun uygulanması suretiyle belirlenen somut cezaya yabancı kanunun göz önünde bulundurulması suretiyle bir sınırlama getirilmektedir. Buna göre, **Türk kanunlarının uygulanması sonucunda belirlenen ceza açısından, yabancı kanunda yargılama konusu suçla ilgili olarak öngörülen soyut cezanın azami ölçü olarak alınması gerekir.***

Ancak, işaret etmek gerekir ki; Türk hâkimi, yurt dışında Türkiye'nin güvenliğine karşı veya zararına olarak ya da Türk vatandaşına karşı veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi zararına olarak işlenen suçlarda münhasıran Türk kanunlarını uygulamak suretiyle hüküm tesis edecek, yani suçun işlendiği ülke kanununu göz önünde bulundurmayacaktır. Aynı şekilde, Türkiye Devleti tarafından görevli olarak yurt dışına gönderilen kişilerin bu görevleri dolayısıyla, bu görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı da ceza belirlenirken yabancı kanun göz önünde bulundurulmayacaktır.”⁸²

⁸² “... yabancı ülkede suç işleyip mahkum edilmediği anlaşılan ve Türkiye’de yargılanan failer hakkında münhasıran Türk Ceza Kanununun uygulanacağı ve suçun işlendiği yerdeki kanunun öngördüğü cezadan daha fazla ceza ile mahkum edilemeyeceği ... gerektiği halde, sanık hakkında ... karşılaştırma yapılmadan hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir”tir: 1. CD, 4.5.2015, E. 2014/3609, K. 2015/2831.

“TCK’nın 19. maddesindeki, Türkiye’nin güvenliğine karşı ve zararına olarak veya Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi zararına işlenmiş suçlar hariç olmak üzere, “Türkiye’nin egemenlik alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye’de yargılama yapılırken, Türk kanununa göre verilecek olan ceza, suçun işlendiği ülke kanununda öngörülen cezanın üst sınırından fazla olamaz” şeklindeki düzenleme karşısında; sanığın iştirak ettiği 18.07.2005 tarihinde Avusturya’da işlenen uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dolayı, Avusturya’nın ilgili kanununda bu suç için öngörülen cezanın üst sınırı belirlendikten sonra, TCK’nın 19. maddesi dikkate alınarak hüküm kurulması gerekirken, eksik araştırma ile karar verilmesi, ... Kanuna aykırı” bulunmuştur: 10.CD, 27.11.2014, E. 2014/3280, K. 2014/13148.

§30. İade

I. Giriş

Çağdaş toplumlarda toplumsal hayatın kompleks bir durum arzemesi ve seri ulaşım araçları nedeniyle belli bir ülkede suç işleyen suçlular izlerini rahatlıkla kaybederek yargılanmaktan veya haklarında hükmolunan cezaların infazından kurtulabilmektedirler. Yine bu seri ulaşım araçları sayesinde belli bir suçun icrasına bir devlet ülkesinde başlanıp, başka bir devlete veya devletlere ait egemenlik alanında devam edilebilmekte ve sonucu da bir başka devlet ülkesinde gerçekleşebilmektedir. Bir devlet ülkesinde icra edilen bir suça başka bir devlet ülkesinde bulunan kişilerin teşvik, yardım veya sair bir surette iştirak etmesi durumları, günümüzde az rastlanan olaylar değildir. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve terörizm gibi bütün toplumlar için müşterek bir tehlike arzeden suçların milletlerarası düzeyde organize suçlu grupları tarafından işlenmesi iadenin milletlerarası ceza adaleti bakımından önemini artırmaktadır⁸³.

II. İade Kavramı, İade Kurumunun Hukuki Dayanağı ve Niteliği, Tarihi Gelişimi

A. Genel Olarak

Kelime olarak iade (geriverme), “*kişinin, ona egemen olana zorla geri verilmesi*” anlamına gelen Latince kökenli “*extradere*”den gelmektedir. İade, bir yabancıya gösterilen geleneksel misafirlğe aykırı, “extra-tradition” (gelenek dışı) bir davranıştır ve sığınma hakkının istisnasını teşkil eder⁸⁴.

Türk hukukunda ilk defa ABD ile 1874 yılında yapılan anlaşmada “extradition” kavramının karşılığı olarak “*istirdad-ı mücrimin*” ibaresi kullanılmıştı⁸⁵. Daha sonra çeşitli devletlerle yapılan iade anlaşmalarında tarihsel gelişime paralel olarak “*iade-i mücrimin*”, “*mücrimlerin iadesi*”, “*suçluların iadesi*” ve “*suçluların geri verilmesi*” kavramları kullanılmıştır. Mülga 765 s. TCK’nın 9. maddesindeki “*iade*” kavramının karşılığı olarak, 5237 s. Türk Ceza Kanununda “*geriverme*” ibaresi kullanılmıştı (m. 18). Ancak bilahare yürürlüğe konan **23.4.2016** tarihli ve 6706 sayılı “**Cezaî Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu**” ile tekrar “*iade*” ibaresi tercih edilmiştir.

⁸³ İade kurumuna ilişkin açıklamalarımızın esasını, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Kayıhan İÇEL’in danışmanlığında hazırlamış bulunduğum “*Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Türk İade Hukukunun Değerlendirilmesi*” başlıklı yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezinde yer alan bilgiler oluşturmaktadır. İade müessesesiyle ilgili bilgi için ayrıca bkz. ERGÜL, Ergin: *Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli*, Ankara, 2003.

⁸⁴ ALPASLAN, M. Şükrü: *Kriminoloji ve Hukuk Açısından Tedhişçilik*, İstanbul, 1983, sh. 246.

⁸⁵ II April 1874 tarihli “Osmanlı Devleti ile Şimali Amerika Müctemiası Arasındaki Tabiiyyet ve İstirdad-i Mücmin Mukavelenamesi”, İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi Muahedeler Tasnifi, no: 76 A-B.

“Suçlu”, mahkeme kararı (hüküm) ile suç işlediği kesin olarak belirlenen kişiyi ifade etmektedir. İade, sadece “suç işlemişler” için değil, fakat suçtan dolayı “şüpheli veya sanıklar” (“zanlılar”) hakkında da söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, “suçluların iadesi” veya “suçluların geriverilmesi” kavramının kullanılması, kurumu eksik olarak ifade etmektedir. Kapsamını daraltmamak için, biz genel olarak “iade” veya “geriverme” kavramlarını kullanmayı tercih etmekteyiz.

İade kurumu yazarlar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bunlar arasından kurumu daha kapsamlı bir şekilde ortaya koyan düşüncüyü⁸⁶ esas alarak bir tanım vermeye çalışacağız:

Ceza işlerinde milletlerarası bir adli yardım kurumu olan iade, bir devlet ülkesinde bulunan kişinin; başka bir devlet ülkesinde işlemiş bulunduğu bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık olması halinde, hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılması amacıyla; hükümlü olması halinde ise, hakkında hükmolunan cezanın infazı amacıyla, yetkili diğer bir devlete, müracaatı üzerine teslim edilmesinden ibaret olan adli ve siyasi bir işlemdir⁸⁷.

Ceza kanunlarının yer itibarıyla uygulama alanı kural olarak devletin ülkesiyle sınırlıdır (mülklik sistemi). Bir devlet ülkesinde suç işledikten sonra başka bir devlet ülkesine kaçan kişi hakkında, ülkesine kaçtığı devlet tarafından soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve suçluların cezalandırılması bakımından istenen sonucu her zaman vermez. Keza, bir devlet ülkesinde işlediği suçtan dolayı mahkum olan kişinin cezası, kural olarak, hükmün verildiği devlet tarafından infaz edilir.

Bir devlet ülkesinde suç işleyip de başka devlet ülkesinde kaçan kişilerin cezasız kalmamaları, ülke topraklarının yabancı suçlulara sığınak teşkil etmemesi için devletlerarasında iade (geriverme) kurumu kabul edilmiştir. Bu kurum, toplumu suç işleyenlere karşı korumak için ceza hukuku uygulamaları bakımından devletlerarasında bir dayanışma ve işbirliği yapılması sonucu ortaya çıkmıştır. Böylece kurumun hukuki dayanağı devletlerin ceza verme hakkına, sosyal fayda ve adalete dayanmaktadır⁸⁸. Ayrıca, söz konusu kurum, ceza kanunlarının yer

⁸⁶ TANER, Tahir: *Ceza Hukuku Umumi Kısım*, İstanbul, 1953, sh.233. *Taner*’in tanımında yer alan kavramlar karşılığında Türk Ceza Hukukuna ilişkin yeni kanunlarda farklı kavramlar kullanıldığı için, tanım aynen alınmamıştır.

⁸⁷ Nitekim yeni TCK’nın 18. maddesinin gerekçesinde şu ifade yer almaktadır:

“Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla, geri verilebilir.”

⁸⁸ TANER, sh. 233-234; DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku*, cilt III, 9. bası, İstanbul, 1983, sh.507-508; ÖZGEN, Eralp: *Suçluların Geri Verilmesi*, Ankara, 1962, sh. 4, 5; İÇEL, Kayıhan: *Suçluların Geri Verilmesi Üzerine Bir İnceleme*, İstanbul ÜHFM, cilt XXX, sayı 3-4, sh.693.

bakımından uygulanmasına ilişkin mülkilik prensibinin sakıncalarını gidermek için ortaya çıkmıştır.

B. Sığınma ve İade İlişkisi

Sığınma; siyasi, dini, felsefi düşünceleri, siyasi faaliyetleri veya bunlarla bağlantılı olarak işlediği bir suç nedeniyle takibe uğrayan bir kişinin yabancı bir devlet ülkesine veya bulunduğu memleketteki yabancı bir devlet temsilciliğine kaçarak korunma isteminde bulunmasıdır. Bunlardan birincisine, “ülkesel sığınma”; ikincisine ise, “ülke dışı diplomatik sığınma” denmektedir⁸⁹.

Tarihi gelişimi itibarıyla sığınma, önceleri sadece adi suçlar için kabul edilmekteydi; buna karşılık, siyasi suçlular için tanınmış değildi. Önceleri, siyasi suçlular ancak karşılıklılık koşuluyla iade edilmekteydiler. Fakat, 19. yüzyıldan itibaren durum değişerek, günümüzde sığınma, sadece siyasi, dini, felsefi düşünce ve faaliyetleri dolayısıyla veya bunlarla bağlantılı olarak suç işledikleri gerekçesiyle takibe maruz kalanların yararlanabilecekleri bir *hak* olarak kabul edilmiştir.

Sığınma, önceleri kişiye tanınmış bir hak olarak görülmeyp, sığınılan devletin sahip bulunduğu bir yetki olarak kabul edilmekteydi⁹⁰. Ancak doktriner gelişmeye paralel olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 14. maddesinin birinci fıkrasıyla sığınma, devletin bir lütfu olmaktan çıkıp, kişi için bir *hak* olarak telakki edilmiştir.

Zulme uğraması sebebiyle ülkesini terk ederek bir başka devlet topraklarına göç eden yabancılara koruma sağlanması, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak düzenlenmiştir (m. 14, f. 1).

Ancak, suç işlemiş olan ve bu sebeple hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasından ya da mahkum olduğu cezanın infazından kurtulmak amacıyla ülkesini terk eden yabancılar, bu haktan kural olarak yararlanamazlar (m. 14, f. 2).

Sığınma, suç işlemiş olan kişinin hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasından ya da mahkum olduğu cezanın infazından kurtulması için bir yol olarak kötüye kullanılmamalıdır^{91, 92}.

⁸⁹ ÇELİK, Edip: *Devletler Hukukunda Diplomatik Melce ve Milletlerarası Adalet Divanı İçtihamı*, İstanbul, 1956, sh.1; ALPASLAN, 252, dn. 168.

⁹⁰ TANER, sh. 241; ÇELİK, sh. 50.

⁹¹ Türkiye, Birleşmiş Milletler “**Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme**”nin tarafıdır. Söz konusu Sözleşme, 29.8.1961 tarihli ve 359 sayılı Kanunla onaylanmıştır. Sözleşme metni, 5 Eylül 1961 tarihli ve 10898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

⁹² “**Mülteci**” (sığınmacı) kavramı, 4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı “**Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu**”nun 61. maddesinde tanımlanmıştır:

“*Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle*

Yukarıda da belirtildiği gibi, sığınma, ülkesel sığınma ve ülke dışı diplomatik sığınma olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki sığınma türü arasında amaç ve nitelik bakımından bir fark bulunmamaktadır. Ancak, iade hukuku bakımından bu iki sığınma türü arasında önemli bir farklılık mevcuttur. Ülkesel sığınmada sığınan kişi, sığınma talebinde bulunduğu devletin ülkesindedir. İade hukukuna ilişkin kuralların uygulama alanı bulduğu bu sığınma türünde, sığınma talebinde bulunan devletin iadeye ilişkin kararı, egemenlik hakkının normal olarak kullanılmasından ibarettir⁹³.

Halbuki ülke dışı diplomatik sığınma halinde, sığınan kişi suçun işlendiği devletin ülkesinde bulunmaktadır. Ülke dışı diplomatik sığınma halinde, sığınma talebi kabul edilmediği takdirde kişi, “teslim etme” usulüyle ülke devletine verilmektedirler⁹⁴. Bu nedenle, iadeye ilişkin iç hukuk ve milletlerarası hukuk kurallarının ülke dışı diplomatik sığınma haline uygulanması mümkün değildir.

korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.”

Söz konusu Kanunda ayrıca “**Şartlı mülteci**” tanımı yapılmıştır.

“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.” (m. 62).

Söz konusu Kanunun “**İkincil koruma**” başlıklı 63. maddesine göre;

“(1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;

- a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,*
 - b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,*
 - c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayırım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak,*
- olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.”*

⁹³ 3 Ekim 1948 tarihinde Peru’da yapılan bir askeri isyana adı karışan Amerikan İhtilalci Halk Birliği lideri Victor Raul Haya de la Torre’nin Lima’daki Kolombiya elçiliğine sığınması üzerine Peru ile Kolombiya hükümetleri arasında çıkan anlaşmazlık üzerine Milletlerarası Adalet Divanının verdiği karar (ÇELİK, age; ERMAN, Sahir: *Siyasi İltica Hakkı*, in: Sos. Huk. ve İkt. Mec., Ocak, 1950 sh. 181).

⁹⁴ RAESTAD, Arnold: *Melce Hakkı* (çev. Tarık E. Yenisey), Ad. Cer., yıl 1938, sh. 1784.

C. İadenin Sınır Dışı Etmeden Farkları

Kişi dokunulmazlığı bakımından, vatandaş ile yabancı arasında kural olarak bir ayırım gözetilmemiştir. Kişi dokunulmazlığı, milletlerarası bildirilerde kabul edilen prensiplere uygun olarak, 1961 ve 1982 Anayasalarında vatandaş ile yabancı arasında fark gözetilmeden düzenlenmiştir. Ancak, “*temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla*” sınırlandırılabilir (1982 Anayasası, m. 16). Kişi dokunulmazlığını hukuka uygun olarak sınırlandıran kurumlardan birisi iade, diğeri ise sınır dışı etmedir⁹⁵.

Her iki kurum bakımından ortak özellik, ancak *yabancılar* hakkında uygulama alanı bulmasıdır⁹⁶. Fakat, her ne kadar iade bakımından milletlerarası alandaki yaygın uygulama bu yönde ise de; günümüzde, vatandaşların da iade edilebileceği kabul edilmektedir. Türk hukuku bakımından, Anayasa’da 2004 yılında yapılan değişiklikle⁹⁷ yumuşatılmış olmakla birlikte, **vatandaşın iade edilmezliği kuralı** varlığını sürdürmektedir.

Buna karşılık sınır dışı etme münhasıran yabancılar hakkında uygulanabilir. 1982 Anayasasının 23. maddesinin son fıkrasında “*vatandaş sınır dışı edilemez*” hükmüne yer verilmiştir.

Bu ortak özelliğine rağmen iki kurum arasında bazı farklar bulunmaktadır. Sınır dışı etme, bir *idari tedbirdir*.

Türk hukukunda **sınır dışı etmenin** esas ve usullerine ilişkin hükümler, **4.4.2013** tarihli ve 6458 sayılı “**Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu**”nda yer almaktadır⁹⁸. Söz konusu Kanuna göre sınır dışı etme kararı, **idari** bir **karardır**. Bu karar, “*valiliklerce*” alınır (m. 53). Söz konusu Kanuna göre bu kararın bizzat vali tarafından alınması gerekmemektedir. Vali bu yetkisini yardımcılarının birine devredebilir. Bu karar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün “*talimatı*” (doğru ifadeyle, talebi) üzerine veya re’sen alınır⁹⁹. Bu kararın, yabancının bulunduğu ilin valiliği tarafından alınması gerekmektedir.

⁹⁵ İÇEL, sh. 694; ÇELİKEL, Aysel: *Yabancılar Hukuku Dersleri*, İstanbul, 1983, sh. 115; ALTUĞ, Yılmaz: *Yabancıların Hukuki Durumu*, İstanbul, 1971, sh. 123 ve son.

⁹⁶ İÇEL, sh. 695; NECATİGİL, Zaim M.: *Suçluların İadesi ve Yabancıların Sınırdışı İşlemleri*, in: Kıbrıs Türk Federe Devletinin Milletlerarası Hukuka İlişkin Bazı Sorunları (Sempozyum, 6-7 Mayıs 1982). İstanbul, 1983, sh.113.

⁹⁷ Anayasanın 38. maddesinin, vatandaşın iade edilmezliği kuralını içeren son fıkrası, 7.5.2004 tarihli ve 5170 sayılı Kanunla değiştirilmiştir (m. 5). Buna göre, “*Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.*”

⁹⁸ RG: 11 Nisan 2013/28695.

⁹⁹ Söz konusu Kanunun “**Sınır dışı etme kararı alınacaklar**” başlıklı 54. maddesi hükmüne göre;

“(1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

Bu kararlar ilgili olarak **özel bir yargı denetimi usulü** belirlenmiştir¹⁰⁰.

- a) 5237 sayılı Kanunun 59'uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,
- b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
- c) Türkiye'ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
- ç) Türkiye'de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
- d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
- e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
- f) İkamet izinleri iptal edilenler,
- g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
- ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
- h) Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
- ı) Hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'ye geldiği tespit edilenler,
- i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayanlar,
- j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayanlar,
- (2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturdıklarına dair ciddi emareler bulunduğu veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.”

Söz konusu Kanunun “**Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar**” başlıklı 55. maddesi hükmüne göre;

“(1) 54'üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

- a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar,
- b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler,
- c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar,
- ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları,
- d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları,
- (2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.”

¹⁰⁰ Danıştay, önceleri sınır dışı etme işlemini, “Hükümet Tasarrufu” olduğunu kabul ederek, idari yargının görev alanının dışında bırakmıştı (Danıştay 5. Dairesinin 12.2.1943 tarih ve 43/343 sayılı kararı). Ancak, 1961 Anayasasının 114. maddesi ile idarenin her türlü eylem ve işlemi yargısal denetime tabi tutulmuştur. Bu suretle, sınır dışı etme işlemlerinin yargı denetimi dışında kalması önlenmiştir. Benzer hüküm, 1982 Anayasasının 125. maddesinin birinci fıkrasında da yer almıştır.

Buna karşılık, hukuk uygulamamızda gerivermeye ilişkin kararlar, yargısal denetime tabi tutulmuştur (DURAN, Lutfi: *Türkiye Hükümetinin Suçluların İadesine Dair Kararları Üzerinde Kazai Murakabe*, in: Tahir Taner'e Armağan, İstanbul, 1956, sh. 609).

Sınır dışı etme kararı, “*gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.*” (6458 s. K, m. 53, f. 2). “*Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, **kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine** başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da **başvurusunu** bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular **on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.** Yabancıнын rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.*” (6458 s. K, m. 53, f. 3)¹⁰¹.

Kanaatimizce sınır dışı etme kararı ile ilgili olarak yapılan “başvuru”, özel usule tabi bir **iptal davası** mahiyeti taşımaktadır. Bu itibarla, söz konusu “başvuru” üzerine idare mahkemesi, **başvurunun reddine** veya **sınır dışı etme kararının iptaline karar** verebilecektir. İdare mahkemesinin söz konusu “başvuru” ile ilgili olarak verdiği karara karşı kanun yolu kapalı tutulmuştur.

Hakkında sınır dışı etme kararı verilen kişi, “*menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye*” gönderilir (6458 s. K, m. 52). Ancak belirtmek gerekir ki, hakkında sınır dışı etme kararı verilmiş olsa bile, kişi “*işken-ceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.*” (6458 s. K, m. 4).

Sınır dışı etme kararının yerine getirilmesine dair usul, söz konusu Kanunun 56 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.

Yeni TCK’da suçtan mahkumiyet halinde sınır dışı etme, önce bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmişti. Ancak Kanunda bilahare yapılan değişikliklerle, suçtan mahkumiyet halinde dahi sınır dışı etme bir *idari tedbir* niteliğini kazanmıştır (m. 59)¹⁰².

¹⁰¹ Bu hükümler, söz konusu Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı 11.4.2013 tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecektir (6458 s. K, m. 125).

¹⁰² Türk Ceza Kanununun 59. maddesi hükmü 31.3.2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce bir **güvenlik tedbiri** yaptırımı içermekteydi. Değiştirilen hükme göre, “*İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancıнын, cezasının infazından sonra derhâl sınır dışı edilmesine de hükmolunur.*”

Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğünün itirazları üzerine bu madde hükmü değiştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, 5328 s. Kanunun TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında sınır dışı etme hususunda kanuni bir zorunluluk getirilmesinin, uygulama bakımından büyük sıkıntılara neden olacağı yönünde endişeler dile getirmişlerdir. Bu endişelere dayalı olarak madde metni değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle, Türk vatandaşı olmayan hükümlünün, cezasının infazı tamamlandıktan sonra, sınır dışı edilip edilmemesi hususu tama-

Buna karşılık, iade kurumu, suçluların cezasız kalmasının önüne geçmek amacına hizmet etmektedir ve bunun için, bir suçtan hükümlü olmak ya da en azından sanık veya şüpheli olmak gerekir. Geriverme, bir devletler hukuku tasarrufu olması nedeniyle, zaman içerisinde adli yönü ağır basan bir nitelik kazanmıştır¹⁰³.

Sınır dışı etme bir devletin tek taraflı kararı ile hüküm ifade etmesine karşılık; gerivermede, taraf olarak iki devletin uyuşmasına, bunun için bir talebe ve de bu talebin kabulüne gerek vardır.

Geriverme için önceden bir anlaşmanın varlığı aranır; buna karşılık sınır dışı etme için bir anlaşmaya gerek yoktur.

D. İade ve “Takas” ilişkisi

Anayasanın 90. maddesinin beşinci fıkrasına 7/5/2004 tarihli ve 5170 sayılı Kanunla (m. 7) bir cümle eklenmiştir:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

Kişinin işlediği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması ya da mahkum olduğu cezanın infazı amacıyla bir devletten bir başka devlete iadesi, kişi hak ve özgürlüklerini ilgilendiren bir husustur. Bu çerçevede kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak amacıyla devletler arasında ikili veya çok taraflı anlaşmalar imzalanarak yürürlüğe konulmaktadır. Bu anlaşmalarda yer alan hükümler, iade prosedürü bağlamında kişi hak ve özgürlüklerini koruyan asgari hükümlerdir.

Bu itibarla iç hukuk düzenlemelerinde, mesela kanunlarda iade prosedürü bağlamında kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir hükme yer verilmesi halinde, Anayasanın 90. maddesinin beşinci fıkrası düzenlemesi karşısında bu hükmün uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır.

Ancak buna rağmen, 17.4.2014 tarihli ve 6532 sayılı Kanunla (m. 6) 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

*“Türk vatandaşları hariç olmak üzere, **tutuklu veya hükümlü bulunanlar**, millî güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hâllerde **Dışiş-***

men İçişleri Bakanlığının takdirine bırakılmıştır. Böylece sınır dışı edilme, bir ceza hukuku yaptırımı olarak güvenlik tedbiri olmaktan çıkıp, bir **idari tedbir** mahiyetine kavuşmuştur.

Sınır dışı edilmenin mahiyetiyle ilgili olarak bkz. GÖZÜBÜYÜK, A. Pulat: *Suçluların Geri Verilmesi Hukukunun Birleştirilmesi ve Geri Verme Umumi Antlaşma Tasarısı*, Ankara, 1949, sh. 11; ÖZGEN, sh. 32; İÇEL, sh. 695.

¹⁰³ İÇEL, sh. 695.

leri Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir.”

Bu düzenleme bir kişinin, iade anlaşmalarının ve iç hukuktaki iade prosedürüne ilişkin hükümlerin bir kenara itilerek, salt **idari** bir **kararla** bir başka devlete **iade** edilebilmesinin yolunu açmaktadır. Bu düzenlemeye “meşruiyet” görüntüsü verebilmek için, fıkra metninde “takas” ibaresine de yer verilmiştir. Oysa iade prosedürü bakımından söz konusu olan, “takas” değil, **karşılıklıdır**. Kişi hak ve hürriyetlerini koruma altına alan iade hukukuna ilişkin hükümleri tamamen bertaraf eden bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından **iptal** edilmiştir¹⁰⁴.

Bu defa, 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı OHAL KHK’si ile (m. 74) 2937 sayılı Kanunun 26. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

*“Türk vatandaşları hariç olmak üzere **tutuklu veya hükümlü bulunanlar**; ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması kaydıyla, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde **Dışişleri Bakanının talebi üzerine Adalet Bakanının teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir** veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir.”*

Bu düzenleme de bir kişinin, koşulları formel olarak “ağırlaştırılmış” (?) olmakla birlikte, kişilere önemli hukuki güvenceler sağlayan iade anlaşmaları ile iç hukuktaki iade prosedürüne ilişkin hükümlerin bir kenara itilerek, salt **idari** bir **kararla** bir başka devlete **iade** edilebilmesine imkan tanımaktadır.

Ancak belirtmek gerekir ki, bu düzenlemenin uluslararası hukukta uygulanabilirliği mevcut değildir. Bu hükümler, ancak Türkiye ile arasında iade anlaşması bulunmayan Kenya, Suudi Arabistan, Malezya ve Burkina Faso gibi henüz Devlet olamamış “devlet”lerden “**paketlemek**” suretiyle, “**at pazarlığı**” yöntemiyle, “**suçlu**” yaftalamasıyla insan transferlerinde uygulanabilir.

17.4.2014 tarihli ve 6532 sayılı Kanunla (m. 6) 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26. maddesine eklenen fıkra hükmünde, birbirleriyle herhangi bir ilgisi olmayan iade ile takas arasında sanki bir ilişki mevcutmuş gibi düzenleme yapılmıştır. Aslında bu düzenleme ile iade hukukunda söz konusu olan **karşılıklılık (mütekabiliyet)** ile “**takas**” birbirine **karıştırılmıştır**.

¹⁰⁴ Any. Mhk., 30.12.2015, E. 2014/122, K. 2015/123 (RG: 1 Mart 2016/29640).

İade hukukunda, kişinin bir suç sebebiyle soruşturulmak veya kovuşturulmak ya da mahkum olduğu cezanın infazı amacıyla bir devletten bir başka devlete iadesine yönelik talep, gerekli **yargısal denetimlerden** geçtikten ve hukuken uygun bulunduktan sonra, bu talebin yerine getirilmesine yönelik olarak verilecek olan siyasi/idari karar ("**Dışışleri ve İçişleri bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanının teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı**") bağlamında karşılıklılık koşulu aranabilir ve aranmaktadır.

Örneğin bir kişinin bir suç sebebiyle Türkiye'den iadesi talep edildiğinde bu talep üzerine ağır ceza mahkemesi "*iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar*" verdiğinde, bu karar temyiz merciinin kanun yolu denetimi sonucunda kesinleşmiş olmasına rağmen, iade talebi hemen yerine getirilmez. İade talebinin yerine getirilebilmesi için, ağır ceza mahkemesinin bu kararı kesinleştikten sonra ayrıca "**Dışışleri ve İçişleri bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanının teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı**" gerekir. Cumhurbaşkanı, Türkiye tarafından iade talep eden devletten bir başka kişi ile ilgili olarak suç sebebiyle iade talebinde bulunulmuş ve bu talep henüz karşı tarafça yerine getirilmemiş ise, söz konusu talebin yerine getirilmesi karşılığında bu kararı verebilir. Bu duruma **iadede karşılıklılık (mütekabiliyet)** denmektedir.

Oysa 2937 sayılı Kanununun 26. maddesinde söz konusu edilen "**takas**"ın iade ve iadede karşılıklılık ilkesiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Örneğin Alman vatandaşı olan bir yabancı, Türkiye'de casusluk, terör örgütüne yardım, terör örgütü üyeliği veya benzeri bir suç işler ve bu suçtan dolayı soruşturulur, kovuşturulur ve hatta cezaya mahkum edilir. Keza, Türk vatandaşı olan bir kişi, görevli olarak bulunduğu Almanya'da bu ülkedeki vatandaşlarımızla ilgili olarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçunu işler ve bu suçtan dolayı bu ülkede soruşturulur, kovuşturulur ve hatta cezaya mahkum edilir.

Almanya Türkiye'den, Türkiye de Almanya'dan tutuklu veya hükümlü olan vatandaşının serbest bırakılmasını ister. Serbest bırakılan kişilerin ülkelerine dönmesi sağlanır. Bir borçlar hukuku kavramı olan ve ceza hukuku alanında hukuk sistemimize ilk defa 17.4.2014 tarihli ve 6532 sayılı Kanunla giren "**takas**" ancak bu durumlarda söz konusu olabilir. Yapılan düzenlemeyle, suç sebebiyle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan bir kişinin, hakkındaki soruşturma ve kovuşturma veya mahkum olduğu cezanın infazı tamamlanmadan, serbest bırakılması ve yurt dışına çıkması sağlanmaktadır. Bu düzenleme, kişinin hükümlü veya tutuklu olmasına rağmen, herhangi bir yargı kararı olmaksızın, salt **idari** bir **kararla**, serbest bırakılmasını ve yurt dışına çıkmasını sağlamaktadır.

Bu düzenleme, örneğin terör örgütünün elinde rehin olarak tutulan kamu görevlilerinin serbest bırakılmasını sağlamak için de kullanılabileceğe benzemektedir.

Ancak bunun için, söz konusu düzenlemeye göre tutuklu veya hükümlü bulunan kişinin **yabancı** olması gerekmektedir.

Ancak, kanaatimizce, terör örgütünün elinde rehin olarak tutulan kamu görevlilerinin serbest bırakılmasını sağlamak için, örgüt üyesi veya yöneticisi olmaktan ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde başka bir suç işlemekten dolayı tutuklu veya hükümlü bulunan bir kişinin serbest bırakılmasının ve yurt dışına çıkmasının sağlanması halinde, tutuklu veya hükümlünün vatandaş veya yabancı olduğuna bakılmaksızın, sorunun kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep olarak TCK'nın **zorunluluk haline** ilişkin hükümleri (m. 25, f. 2) çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Söz konusu düzenleme, örneğin 15 Temmuz 2016 tarihinde işlenen “darbeye” teşebbüs suçuna iştirakten dolayı Türkiye’de hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan ve İzmir’de tutuklu bulunan yabancı uyruklu “**Papaz**”ın serbest bırakılıp yurt dışına çıkmasını sağlamak karşılığında; aynı suça iştirak ettiği iddia edilen ve fakat yurt dışında bir başka devlet ülkesinde bulunan vatandaş “**İmam**”ın iadesi talep edildiğinde; bu hüküm, söz konusu “*İmam*”ın Türkiye’ye iadesi yönündeki talebin yerine getirilmesini mümkün kılmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi tarafından, 2937 sayılı Kanunun 26. maddesine 6532 sayılı Kanunla eklenen söz konusu fıkra hükmü iptal edilirken, gerekçede bu ayrımların ve farklı durumların hiçbirine yer verilmemiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptali üzerine, 2937 sayılı Kanunun 26. maddesine 694 sayılı OHAL KHK’si ile eklenen fıkra düzenlemesi de, iade ile “takas” arasında bir ayırım gözetmemesi ve söz konusu durumların her biri ile ilgili olarak farklı hükümler içermemesi dolayısıyla sorunludur ve maluldür.

Anayasa Mahkemesinin iptali üzerine, 2937 sayılı Kanunun 26. maddesine 694 sayılı OHAL KHK’si ile eklenen fıkra düzenlemesi, bir bakıma **hileli bir düzenlemedir**. Şöyle ki, iade halinde iade edilen kişi iade edildiği devlette soruşturulur, kovuşturulur veya mahkum olduğu ceza infaz edilir. Oysa “takas” halinde, “takas” çerçevesinde serbest bırakılan ve yurt dışına çıkması sağlanan kişinin, bir başka devlet tarafından soruşturulması ve kovuşturulması ve keza, mahkum olduğu cezanın bir başka devlette infazı söz konusu değildir. Kısaca belirtmek gerekirse, “takas” edilen kişi tamamen serbest bırakılmaktadır.

Oysa, 2937 sayılı Kanunun 26. maddesinin 694 sayılı OHAL KHK’si ile yeniden düzenlenen söz konusu hükmü, adeta “takas” edilen kişinin de gönderildiği devlette soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulacağı izlenimi oluşturacak şekilde kaleme alınmıştır. Buna göre, örneğin Türkiye’de tutuklu veya hükümlü bulunan yabancı, “*ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması kaydıyla, ... başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir.*”

Bu özelliği itibarıyla söz konusu düzenleme ile adeta **Anayasa Mahkemesine karşı hile** yapılmıştır.

Türkiye’de hakkında soruşturma veya kovuşturma süreci devam eden bir yabancının, bu soruşturma veya kovuşturma nihai kararlar sonuçlanıncaya kadar yurt dışına çıkışına hukuken izin verilemez. Meğer ki kişi kovuşturma evresinde duruşmadan vareste tutulmuş olsun. Aksi takdirde, yani hakkında soruşturma veya kovuşturmanın devam etmesine rağmen yurt dışına çıkışına müsamaha gösterilen yabancının Türkiye’de yargılamasına devam edilmesi, abesle iştigal olur.

Bu durum, başka bir devlette hakkında soruşturma veya kovuşturma süreci devam eden bir vatandaş ile, Türkiye’de hakkında soruşturma veya kovuşturma süreci devam eden bir yabancının “takas” edilmek istenmesi halinde de söz konusudur. Esasında, hakkındaki soruşturma ve kovuşturma devam ederken, bu soruşturma ve kovuşturma henüz nihai kararlar sonuçlanmadan önce şüpheli veya sanığın idari kararlar “takas”ına imkan tanıyan kanuni düzenlemenin, hukukla telifi kabil değildir.

Bu itibarla, malum “**Papaz**” gibi bir yabancının, Türkiye’de hakkında soruşturma ve kovuşturma süreci devam ederken, serbest bırakılması sağlanıp yurt dışına çıkışına izin verilmesinin, hukukla telifi kabil bir yönü bulunmamaktadır.

Bu olaylar, her daim olduğu gibi, Türk yargısının “bağımsız”lığının sorgulanmasını mucip olmuştur. Siyasetin yargıyı etkileme girişimleri, arzu edilmese bile, her zaman karşılaşılan bir durumdur. Ancak Türkiye bakımından her daim en önemli sorun, yargının kendisini siyasetin etkisine açık tutmasıdır.

Dikkat edilmelidir ki, bu açıklamalar şüpheli ve sanıkla ilgilidir. Hükümlü ile ilgili olarak farklı bir yöntem izlenmesi gerekir.

Türkiye’de yargılanarak bir cezaya mahkum edilmiş olan yabancı hükümlü, milletlerarası sözleşmelerin ve 6706 s. Kanunun hükümlülerin nakline veya cezanın infazına ilişkin hükümleri dışında da, cezasının infazı tamamlanmadan ve hatta infazına başlanmadan **sınır dışı edilme işlemine tabi tutularak yurt dışına çıkışına izin verilebilmelidir**. Bu yola, özellikle **Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin gerekli kılması halinde** başvurulabilmelidir. Dikkat edilmelidir ki, yabancı hükümlünün sınır dışı edilme işlemine tabi tutularak yurt dışına çıkışına izin verilmesi, Türkiye’de mahkum olduğu kesinleşen cezasının infazı amacına matuf değildir. Başka bir ifadeyle bu kişinin cezasının infazı, tekrar Türkiye’ye gelmediği takdirde, mümkün olmayacaktır. Belirtmek gerekir ki, sınır dışı etme, **yabancının iradesi dışında** gerçekleşen bir idari işlem ve tasarruftur. Oysa bu durumda yabancı hükümlünün, Türkiye’de mahkûm olduğu cezanın infazından kurtulmasını sağlamak için, yurt dışına çıkışına izin verilmektedir. Bu nedenle, söz konusu durum salt sınır dışı etmeden farklılık arz etmektedir. Ancak, bu suretle yurt dışına çıkışına izin verilen kişinin bilahare tekrar Türkiye’ye gelişine de bir tıkım so-

nuçlar bağlamak gerekir. Yani Türkiye’de hükümlü olan yabancının cezasının infazı tamamlanmadan ve hatta infazına başlanmadan sınır dışı edilme işlemine tabi tutularak yurt dışına çıkışına izin verildikten sonra **tekrar Türkiye’ye gelmesi halinde cezası infaz edilmelidir**. Aksi takdirde, Devlet egemenliği ile bağdaşmayan önemli bir kötüye kullanmanın yolu açılmış olur.

Yabancı hükümlünün bu yolla yurt dışına çıkışı için, belirli bir usul çerçevesinde **idari kararın** verilmesi yeterli olmalıdır. Yabancı hükümlünün bu yolla sınır dışı edilebilmesi için karşılıklılık şartı aranmasına bile gerek olmayabilir. Bu amaçla mevzuatımızda özel bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmaktadır. Ancak bu düzenlemenin yeri, 1937 s. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu değil, 5275 s. İnfaz Kanunu olmalıdır. 1937 s. Kanunun 26. maddesi düzenlemesi, bu ihtiyaca cevap verebilecek bir içeriğe sahip değildir.

Mevzuatımızda bu amaca hizmet edecek bir hükmün bulunmaması sebebiyle, geriye izlenebilecek bir “yol” kalmaktadır: Cezasını çekmek üzere infaz kurumunda bulunan yabancı hükümlünün, Devletin uluslararası ilişkilerinin gerekli kıldığı durumlarda, görünüşte “**firari**” muamelesine tabi tutularak, infaz kurumundan çıkarılmasının ve yurt dışına çıkışının sağlanması (!?).

E. İade Kurumunun Tarihi Gelişimi

İade kurumu, milletlerarası hukukun gelişiminin ve devletler arasındaki adli yardımlaşma ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Önceleri devletler arasında gerivermeye ilişkin genel sözleşmeler mevcut değildi ve sadece siyasi suçlar dolayısıyla iade yolu işletilmekteydi¹⁰⁵. 17. yüzyıldan itibaren adi suçlar da iade kapsamına alınmaya başlanmıştır¹⁰⁶.

19. yüzyıldan itibaren, devletler, adi suçluların iadesini suçla savaş bakımından kendi yararlarına olduğunu kabul ederek, bu hususta karşılıklı anlaşmalar imzalamaya yoluna gitmişlerdir¹⁰⁷. Yine, siyasi suçluların iade edilmemesi yönündeki düşünce gelişerek 19. yüzyılın ikinci yarısında bir devletler hukuku prensibi halini almıştır¹⁰⁸.

19. yüzyıldan itibaren, devletler arasında genel iade anlaşmaları imzalanmaya başlanmıştır. Artık devletler belirli şartlar gerçekleştiği takdirde, sübjektif olay üzerinde durmaksızın iadede bulunmayı karşılıklı olarak yükümlenmişlerdir¹⁰⁹.

¹⁰⁵ TANER, sh. 109; ARMAOĞLU, Fahir Hadi: *Belçika Kaidesi ve Siyasal Suçluların İadesi Meselesi*, Adalet Dergisi, 1951, sh. 1596.

¹⁰⁶ DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 504

¹⁰⁷ ÖZGEN, sh. 20; İÇEL, sh. 698.

¹⁰⁸ ARMAOĞLU, sh. 1597; ÖZGEN, sh. 80.

¹⁰⁹ DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 504.

Devletlerarasında ortak ve genel bir iade sözleşmesi hazırlanması konusunda milletlerarası düzeyde çeşitli çalışmalar yapılmıştır¹¹⁰. Ancak bu çalışmalardan şimdilik olumlu sonuca ulaşan sadece Avrupa Konseyi olmuştur. Konsey'e üye devletler tarafından 13 Aralık 1957 tarihinde “**Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi**” (ETS 24) imzalanarak devletlerin onayına sunulmuştur. Ayrıca bu Sözleşmede birtakım değişiklikler yapan ve yeni hükümler içeren (1.) **Ek Protokol** (ETS 86) 15.10.1975 tarihinde, **2. Ek Protokol** (ETS 98) 17.3.1978 tarihinde, **3. Ek Protokol** (ETS 209) 10.11.2010 tarihinde ve **4. Ek Protokol** (ETS 212) 20.9.2012 tarihinde imzalanmıştır.

III. İade Hukukunun Kaynakları ve Birbirleriyle İlişkisi

A. İade Hukukunun Kaynakları

Milletlerarası adli yardım kurumu olan iadenin işleyebilmesi için, iki devlet arasında barış esasına dayalı diplomatik ilişkinin mevcudiyeti gereklidir. Ayrıca, devletler arasında sübjektif olayın dışında, objektif ve genel nitelikte bir **iade anlaşmasının** bulunması gereklidir¹¹¹. Ancak, belirtmek gerekir ki, iki devlet arasında imzalanıp onaylanmış genel bir iade anlaşmasının olmaması halinde de geriverme mümkündür. Fakat, bu durumda, talepte bulunulan devlet açısından geriverme hususunda bir yükümlülükten söz edilemez.

Uygulamada 19. yüzyıldan itibaren, iade hukukuna ilişkin düzenlemeler iki taraflı anlaşmalarla yapılmaktadır.

Ancak iade kurumunun ceza ve ceza muhakemesi kanunları ile sıkı ilişki içinde olması ve devletlerin bu konudaki düzenlemelerinin birbirinden farklı olması nedeniyle, gerivermeye ilişkin iki taraflı anlaşmalar arasında da doğal olarak bir çok ayrılıklar meydana çıkmaktadır. Hatta bir devletin çeşitli devletlerle imzaladığı iade anlaşmaları da pek çok noktada birbirleriyle farklılık arz etmektedir¹¹².

Bu sakıncaların giderilmesi, iade hukukuna ilişkin genel prensipler bakımından iki taraflı anlaşmalar ve iç hukuk düzenlemeleri arasında ahenk ve yeknesaklık sağlanması¹¹³ ve böylece milletlerarası suçluluğun daha etkin bir şekilde önlenmesi¹¹⁴ amacıyla, devletler arasında genel bir iade anlaşması hazırlanması gerektiği teorik planda¹¹⁵ ileri sürüldüğü gibi; bu amaçla milletlerarası düzeyde birçok kongre

¹¹⁰ Bu çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. GÖZÜBÜYÜK, A, Pulat: *Devletlerarası Ceza Hukuku*, Ankara, 1959, sh. 91 ve son.; aynı yazar, (Suçluların...) sh. 14 ve son; TEZCAN, Durmuş: *Territorialite Et Conflits De Juridictions En Droit Penal International*, Ankara, 1983, sh. 244.

¹¹¹ ÖZGEN, sh. 7 ve son.; İÇEL, sh. 703.

¹¹² TANER, sh. 235; MERAY, Seha L.: *Devletler Hukukuna Giriş*, cilt 1, Ankara, 1959 sh. 432.

¹¹³ TANER, sh. 235, ÖZGEN, sh. 24.

¹¹⁴ GÖZÜBÜYÜK (Suçluların...), sh. 4.

¹¹⁵ GÖZÜBÜYÜK (Suçluların...), sh. 14.

ve konferans düzenlenmiştir¹¹⁶. Söz konusu kongre ve konferanslarda iki veya çok taraflı anlaşmalarda esas alınmak üzere tip anlaşma taslakları hazırlanmıştır.

İadeye ilişkin iç hukuktaki düzenlemeler de farklılık arz etmektedir. Bazı devletler ceza kanunları bünyesinde iade kurumuna ilişkin hükümlere yer vermiştir. Ancak, bu düzenlemeler, eksiktir ve kuruma ilişkin pek çok hususun çözümlemesini sağlayamamaktadır. Bu eksikliklerin, özel hükümlerin bulunmadığı yerlerde genel hükümlerin uygulanacağı kuralından hareketle giderilebileceği ileri sürülmekteyse de; iade hukukunun kendine özgü (“nev’i şahsına münhasır”, “sui generis”) özellik arz etmesi nedeniyle, özel düzenleme bulunmayan hususlarda genel hükümlerin uygulanması çoğu zaman iyi sonuçlar vermemektedir¹¹⁷.

İade hukukuna ilişkin ilk genel milletlerarası bir metin olan “*Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi*”ni onaylayan devletler, diğer devletlerle imzaladıkları iki taraflı iade anlaşmalarında söz konusu Sözleşme hükümlerine uygun hareket ettikleri gibi; iç hukuk düzenlemesi olan özel iade kanunlarını da bu Sözleşmedeki genel hükümlere uygun bir biçimde yeni baştan kaleme almaktadırlar. Daha önce özel bir iade kanununa sahip olmasına rağmen Avusturya, söz konusu Sözleşmenin genel kuralları doğrultusunda hazırladığı yeni “*Suçluların İadesi ve Adli Yardım Kanunu*”nu 1.7.1980 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Yine daha önce özel bir iade kanununa sahip olmasına rağmen, İsviçre ve Almanya’da söz konusu Sözleşme hükümlerini örnek alan yeni bir iade kanunu hazırlama çalışmaları bulunmaktadır¹¹⁸.

Türkiye, **Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesini (SİDAS)** onaylamış ve yürürlüğe koymuştur¹¹⁹. Bu suretle söz konusu Sözleşme, Türk iade hukukunun önemli bir kaynağı haline gelmiştir^{120, 121}.

¹¹⁶ Ayrıntılı bilgi için bkz. GÖZÜBÜYÜK (Suçluların...), sh. 14 ve son.

¹¹⁷ TANER, sh. 235; ÖZGEN, sh. 111.

¹¹⁸ YENİSEY, Feridun: *Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma*, in: Ad. Der. 1981 sayı 4, sh. 590.

¹¹⁹ Söz konusu Sözleşme, 18.11.1959 tarihli ve 7376 sayılı Kanunla onaylanmıştır. Onay Kanunu ve Sözleşme metni, 26 Kasım 1959 tarihli ve 10365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹²⁰ Söz konusu Sözleşmenin, Türkiye’nin yanı sıra, **taraf olarak ilgili devletler bakımından da yürürlüğe girmesi üzerine**,

a) Türkiye Cumhuriyeti ile **İtalya** Krallığı Arasında Mün’akit İade-i Mücrimin Muahedenamesi (Onay K. no: 1305. Sözleşme metni için bkz. RG: 13.12.1928/1065),

b) Türkiye ile **İsviçre** arasında Mücrimlerin İadesine ve Cezai Mevatta Karşılıklı Müzaheretli Adliyeye Mütteallik Muahedename (Onay K. no: 2535, tarih: 23.06.1934. Sözleşme metni için bkz. RG: 04.07.1934/2743),

c) Türkiye-**Belçika** arasında İade-i Mücrimin Muahedenamesi (Onay K. no 3647, tarih: 16.05.1939. Sözleşme metni için bkz. RG: 22.06.1939/4239),

ç) Türkiye-**Yunanistan** arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Cezai Sahada Karşılıklı Adli Yardım Muahedenamesi (Onay K. no 3755, tarih: 20.12.1939. Sözleşme metni için bkz. RG: 27 Kanunuevvel 1939/4395),

Keza Türkiye, **Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolü 1991** yılında onaylamış ve yürürlüğe koymuştur.¹²²

Türkiye ayrıca, **Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine (1.) Ek Protokolü, 3. Ek Protokolü ve 4. Ek Protokolü 2016** yılında onaylamış ve yürürlüğe koymuştur.¹²³

SİDAS ve söz konusu Ek Protokoller, aşağıda zikredeceğimiz diğer iade anlaşmalarından farklı olarak çok taraflı anlaşma niteliği taşımaktadırlar. Mahiyetleri gereği olarak bu anlaşma hükümleri ancak taraf devletler arasında uygulanabilir. Başka bir ifadeyle, SİDAS ve söz konusu Ek Protokoller, ancak Türkiye ile

d) Türkiye ile **Bulgaristan** arasında İadei Mücrimin Mukavelenamesi (Onay K. no: 1649, tarih: 26.05.1930. Sözleşme metni için bkz. RG: 09.06.1930/1515),

e) Türkiye Cumhuriyeti ile **Macaristan** Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Anlaşmasının (Onay K. no: 2650, tarih: 26.03.1982. Sözleşme metni için bkz. RG: 5 Ağustos 1982/17773) **suçluların iadesine ilişkin hükümleri**,

f) Türkiye Cumhuriyeti ile **Yugoslavya** Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi (Onay K. no: 1832, tarih: 9.7.1974. Sözleşme metni için bkz RG: 01 Kasım 1974/15049)

g) Türkiye Cumhuriyeti ile **Polonya** Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin (Onay K. no: 3636, tarih: 19.4.1990. Sözleşme metni için bkz. RG: 07 Ekim 1990/20658) **suçluların iadesine ilişkin hükümleri**,

ğ) Türkiye ve **Çekoslovakya** arasında İadei Mücrimin ve Ceza İşlerinde Adli Müzaheret Muahedenamesi (Onay K. no: 2055, tarih: 02.07.1932. Sözleşme metni için bkz. RG: 09 Temmuz 1932/2145),

h) Türkiye Cumhuriyeti ile **Almanya** Devleti Arasında İadei Mücrimin Muahedesi (İmza tarihi: 3 Eylül 1930. Onay K. no: 1800, tarih: 26.03.1931. Sözleşme metni için bkz. RG: 06.04.1931/1767). Bu Sözleşmenin 1 Mart 1952 Tarihinden İtibaren Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkında Notalar (26 Şubat 1952 tarih ve 3/14511 sayılı Kararname. RG: 3 Mayıs 1952/8100). Mücrimlerin İadesine Dair 3 Eylül 1930 Tarihli Türkiye Almanya Anlaşmasının 19'uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Mektup Teatisi Suretiyle Yapılan Anlaşma (Onay K. no: 806, tarih: 8.12.1966. Sözleşme metni için bkz. RG: 21 Aralık 1966/12483),

ilga olmuştur.

Ayrıca **Yugoslavya** Sosyalist Federatif Cumhuriyeti'nin de hukuki varlığı sona erdiği için, Türkiye Cumhuriyeti ile bu devlet Arasında Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi de yürürlükten kalkmıştır. Ancak, bu devlet toprakları üzerinde kurulan diğer bütün devletler Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesini onaylayarak yürürlüğe koymuşlardır.

¹²¹ Söz konusu Sözleşmenin hazırlık süreci ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ULUTAŞ, Ahmet: *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Suçluların Geri Verilmesi*, Ankara, Ekim 2012).

¹²² Söz konusu **İkinci Ek Protokol** metni, 25 Eylül 1991 tarihli ve 21002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹²³ Söz konusu **1. Ek Protokol** metni, 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu **3. Ek Protokol** metni, 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu **4. Ek Protokol** metni, 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

bunları onaylayan diğer devletler arasındaki iade ilişkilerinde uygulanabilirliği haizdir. Bu itibarla her bir somut olay bağlamında SİDAS ve söz konusu Ek Protokollerin, Türkiye'nin yanısıra, iade talep eden veya iade talep edilen devlet tarafından da onaylanmış olup olmadığını araştırmak gerekir¹²⁴.

Türk hukukunda, iade kurumuna ilişkin çeşitli tarihlerde değişik devletlerle imzalanmış iki taraflı anlaşmalar bulunmaktadır. Bu anlaşmalardan bir kısmı tarihi gelişim süreci içinde kısmen veya tamamen değişikliklere uğratılarak yerlerine yenileri ikame edilmiştir. Bu anlaşmalardan bir kısmı münhasıran geriverme kurumuna ilişkin bulunmaktadır; bir kısmı ise, ceza ve hatta hukuki konularda adli yardım hükümlerinin yanı sıra iade müessesesine ilişkin hükümler içermektedir. Geriverme kurumuna ilişkin hükümlerin yer aldığı ve yürürlükte olan **bütün ikili iade ve cezai konularda adli yardım anlaşmaları** tarih sırası itibarıyla şunlardır:¹²⁵

1. Türkiye Cumhuriyeti ile **Irak** Krallığı Arasında İade-i Mücrimin Muahedenamesi (Sözleşme metni için bkz. RG: 5 Temmuz 1932/2142). Ayrıca; Türkiye Cumhuriyeti ile **Irak** Krallığı Arasında Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi - Türkiye ile Irak Arasında 29 Mart 1946 Tarihli Dostluk ve İyi Komşuluk Anlaşması'na Ek- (Sözleşme metni için bkz. RG: 12.09.1947/6705).
2. Türkiye Cumhuriyeti ile **Romanya** Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai İşlerde Adli Yardım Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 17 Mayıs 1972/14190).
3. Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi **Ürdün** Krallığı Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 11 Ağustos 1975/15323).
4. Türkiye Cumhuriyeti ile **Bulgaristan** Halk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 24 Mayıs 1978/16296).
5. Türkiye Cumhuriyeti ile **Amerika Bileşik Devletleri** Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 20 Kasım 1980/17166)¹²⁶.
6. Türkiye Cumhuriyeti ile **Amerika Bileşik Devletleri** Arasında Ceza Yargılamasının Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşma (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 20 Kasım 1980/17166).

¹²⁴ Bu araştırma her defasında güncel olarak Avrupa Konseyine ait internet sitesinden, “**Treaty Office – Council of Europe**” üzerinden yapılmalıdır.

¹²⁵ Bütün bu sözleşme metinlerine, ayrıca, www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/ikili.html internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

¹²⁶ Söz konusu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine, Türkiye ile Amerika Düvel-i Müttehidesi Beyninde İade-i Mücrimin Muahedenamesi (İmza tarihi: 06.08.1823. Onay K. no: 2404, tarih: 07.04.1934. Sözleşme metni için bkz. RG: 15.04.1934/2676), yürürlükten kaldırılmıştır.

7. Türkiye Cumhuriyeti ile **Macaristan** Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 5 Ağustos 1982/17773)¹²⁷.
8. Türkiye Cumhuriyeti ile **Tunus** Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 20 Şubat 1983/17965).
9. Türkiye Cumhuriyeti ile **Pakistan** İslam Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 16 Mart 1983/17989).
10. Türkiye Cumhuriyeti ile **Suriye** Arab Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 18 Mart 1983/17991. Anlaşmanın Türkçe metnindeki bazı maddi hatalar düzeltilerek; Anlaşma metni, 15 Eylül 1983 tarihli ve 18166 sayılı Resmi Gazetede yeniden yayınlanmıştır.)¹²⁸. **Lübnan** ile ülkemiz arasında suçluların geri verilmesi alanında ayrı bir sözleşme bulunmamakla beraber, Suriye ile imzalanan bu Anlaşma Lübnan için de geçerlidir.
11. Türkiye Cumhuriyeti ile **Pakistan** İslam Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 3 Eylül 1984/18508).
12. Türkiye Cumhuriyeti ile **Libya** Sosyalist Arap Halk Cemahiriyesi Arasında Suçluların Geri Verilmesine Dair Sözleşme (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 2 Haziran 1987/19475).
13. Türkiye Cumhuriyeti ile **Mısır** Arap Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Transferine Dair Sözleşme (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 3 Temmuz 1987/19506).
14. Türkiye Cumhuriyeti ile **Macaristan** Halk Cumhuriyeti Arasında Cezai Meselelerde Adli Kararların Karşılıklı Olarak İnfazına Dair Sözleşme (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 18 Temmuz 1987/19521).
15. Türkiye Cumhuriyeti ile **Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti** Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 13 Şubat 1989/20079).

¹²⁷ Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi Macaristan bakımından 11.10.1993 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Anlaşmasının suçluların iadesine ilişkin hükümleri ilga olmuştur.

¹²⁸ Söz konusu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine, Türkiye-Suriye (Fransa) arasında Mücrimlerin İadesine, Cezai İşlerde Adli Evrakın İrsaline ve İstinabelerin İcrasına Mütteallik 1 numaralı Protokol (Onay K. no: 3888, tarih: 17.06.1940. Sözleşme metni için bkz. RG: 22.06.1940/4552), yürürlükten kaldırılmıştır.

16. Türkiye Cumhuriyeti ile **Mısır** Arap Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 7 Ekim 1990/20658 Mükerrer).
17. Türkiye Cumhuriyeti ile **Hindistan** Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 7 Ekim 1990/20658 Mükerrer).
18. Türkiye Cumhuriyeti ile **Fas** Krallığı Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 7 Ekim 1990/20658 Mükerrer).
19. Türkiye Cumhuriyeti ile **Polonya** Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 7 Ekim 1990/20658)¹²⁹.
20. Türkiye Cumhuriyeti ile **Cezayir** Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 21 Mayıs 1991/20877).
21. Türkiye Cumhuriyeti ile **Irak** Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 2 Ağustos 1992/21303).
22. Türkiye Cumhuriyeti ile **Azerbaycan** Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 25 Ağustos 1993/21679).
23. Türkiye Cumhuriyeti ile **Çin** Halk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 12 Kasım 1994/22109).
24. Türkiye Cumhuriyeti ile **Romanya** Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline İlişkin Sözleşme (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 14 Kasım 1994/22111).
25. Türkiye Cumhuriyeti ile **Bulgaristan** Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Transfere Dair Sözleşme (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 14 Kasım 1994/22111).
26. Türkiye Cumhuriyeti ile **Kazakistan** Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 17 Ağustos 1997/23083).
27. Türkiye Cumhuriyeti ile **Gürcistan** Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 24 Ağustos 1997/23090).

¹²⁹ Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi Polonya bakımından 13.9.1993 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin suçluların iadesine ilişkin hükümleri ilga olmuştur.

28. Türkiye Cumhuriyeti ile **Özbekistan** Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 7 Kasım 1997/23163).
29. Türkiye Cumhuriyeti ile **Arnavutluk** Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi (Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 9 Kasım 1997/23165).
30. Türkiye Cumhuriyeti ve **Makedonya** Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 14 Mayıs 2000/24049).
31. Türkiye Cumhuriyeti ve **Moldova** Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 28 Mayıs 2000/24062).
32. Türkiye Cumhuriyeti ile **Kuveyt** Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ticaret ve Ceza Hukuku Konularında Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 30 Mayıs 2000/24064).
33. Türkiye Cumhuriyeti ile **Tacikistan** Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması. (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 30 Mayıs 2000/24064).
34. Türkiye Cumhuriyeti ile **Avustralya** Arasında Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 21 Ocak 2001/24294).
35. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile **Hindistan** Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 12 Ağustos 2003/25197).
36. Türkiye Cumhuriyeti ile **Moğolistan** arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 4 Mayıs 2004/25452).
37. Türkiye Cumhuriyeti ile **Umman** Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 22 Mayıs 2010/27588).
38. Türkiye Cumhuriyeti ile **Kırgız** Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 5 Temmuz 2011/27985 Mükerrer).
39. Türkiye Cumhuriyeti ile **İran** İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması. Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 5 Temmuz 2011/27985 Mükerrer)¹³⁰.

¹³⁰ Söz konusu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti ile İran arasında İadei Mücrimin ve Cezai Mevadda Adli Müzaheret Muahedenamesi (Onay K. no: 3213, tarih:

40. Türkiye Cumhuriyeti ile **Türkmenistan** Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 22 Mayıs 2013/28654).
41. Türkiye Cumhuriyeti ile **Kazakistan** Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 6 Mayıs 2015/29347).
42. Türkiye Cumhuriyeti ile **Brezilya** Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 3 Haziran 2015/29376).
43. Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif **Brezilya** Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 4 Haziran 2015/29376).
44. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile **Kosova** Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 22 Mart 2016/29661).
45. Türkiye Cumhuriyeti ile **Rusya** Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 6 Haziran 2017/30088 Mükerrer).
46. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik **Meksika** Devletleri Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar ve Terörizmle Mücadelede İş Birliği Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 23 Haziran 2017/30105 Mükerrer).
47. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik **Meksika** Devletleri Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Uluslararası Ticaretiyle Mücadele Alanında İş Birliği Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 7 Haziran 2017/30089 Mükerrer).
48. Türkiye Cumhuriyeti ile **Bosna Hersek** Arasında İade Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 6 Haziran 2017/30088).
49. Türkiye Cumhuriyeti ile **Bosna Hersek** Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 24 Ağustos 2017/30164).
50. Türkiye Cumhuriyeti ile **Belarus** Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 31 Temmuz 2017 /30140 Mükerrer).
51. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile **Kosova** Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşması” ile söz konusu Anlaşmaya ilişkin “Notalar” (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 26 Şubat 2018/30344 Mükerrer).

07.06.1937. Sözleşme metninin yayımlandığı RG: 21.06.1937/3636), yürürlükten kaldırılmıştır.

52. “Türkiye Cumhuriyeti ile **Sırbistan** Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması” (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 19 Mart 2018/30365 Mükerrer)

53. “Türkiye Cumhuriyeti ile **Sırbistan** Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesine Dair Anlaşma” (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 10 Mayıs 2019/30770 Mükerrer)

54. “Türkiye Cumhuriyeti ve **Hırvatistan** Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması” (Anlaşma metninin yayımlandığı RG: 2 Haziran 2021/31499)

Bunların yanı sıra, düzenleme alanları birbirinden farklı olmakla beraber, iade hukukuna ilişkin hükümler taşıyan Türkiye’nin taraf olduğu çok taraflı anlaşmalar da kaynaklar arasında mütalaa edilmelidir.

İç hukuk düzenlemesi olarak mülga 765 s TCK’nın 9. maddesinde iade hukukuna ilişkin genel ve fakat yetersiz hükümler bulunmaktaydı. Söz konusu maddede yer alan hükümler, şu şekilde sıralanabilir:

- a) Ancak “cürüm”lerden dolayı iade yoluna gidilebilir.
- b) Vatandaş geri verilemez.
- c) Siyasi veya askeri ya da bunlarla bağlantılı suçlardan dolayı iade yoluna gidilemez.
- ç) Geriverme talebi üzerine, asliye ceza mahkemesinin,
 - 1. İadesi istenen kişinin Türk Vatandaşı olup olmadığı,
 - 2. İade talebinin sebebini oluşturan suçun nitelik bakımından iade kapsamına girip girmediği,hususlarını tespit yönünde bir karar vermesi gerekir.
- d) İadesi istenen kişinin Türk vatandaşı olmadığı ve iade talebinin sebebini oluşturan suçun nitelik bakımından adi suç olduğunun mahkemece tespit edilmesi halinde; ayrıca hükümetçe, kişinin iade edilmesi yönünde karar verilmesi gerekmektedir.
- e) İadesi yönündeki talebin hükümetçe kabul edilmesi halinde, kişinin tutuklanmasına karar verilebilecektir.

Yeni TCK’nın 18. maddesinde de iade kurumuna ilişkin hükümlere yer verilmiştir. TCK Tasarısına ilişkin olarak TBMM Adalet Alt Komisyonundaki çalışmalarımız sırasında, iade kurumuna ilişkin düzenlemelerin, bu kuruma özgü bir kanunda yapılması hususu tarafımızdan gündeme getirilmiştir. Ancak, siyasi irade, geriverme konusunda ayrı bir kanun yapılmasına gerek olmadığı, iadeye ilişkin olarak iç hukukta yapılması gereken düzenlemelerin TCK kapsamında yer almasının uygun olacağı yönünde oluşmuştu. Bu siyasi iradeye paralel ola-

rak, iade kurumuna ilişkin olarak iç hukukta yer alması gereken hükümler, TCK'nın 18. maddesinde düzenlenmişti¹³¹.

Ancak TCK'nın söz konusu maddesi, **23.4.2016** tarihli ve 6706 sayılı “**Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu**”¹³² ile yürürlükten kaldırılmış ve bu madde hükümleri söz konusu Kanuna aktarılmıştır.

Söz konusu madde düzenlemesinde, 765 sayılı TCK'da olduğu gibi, esas itibarıyla, **Türkiye’den iade talebinde bulunulması haline ilişkin** hükümlere yer verilmişti. Türkiye’nin başka bir devletten iade talebinde bulunulması haline ilişkin olarak ise, söz konusu maddede sadece **iadede hususilik kuralı** düzenlenmişti. Söz konusu maddede şu hükümlere yer verilmişti:

a) Türkiye’den iade talebinde bulunulması halinde, iade sebebini oluşturan fiilin Türk kanunlarına göre de suç oluşturması gerekir.

¹³¹ “Geri verme

MADDE 18- (1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza soruşturması ya da kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, soruşturma ya da kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla, geri verilebilir. Ancak, geri verme talebine esas teşkil eden fiil;

a) Türk kanunlarına göre suç değilse,

b) Düşünce suçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğinde ise,

c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse,

d) Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç ise,

e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise,

Geri verme talebi kabul edilmez.

(2) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

(3) Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde, ırkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle soruşturulacağına ya da kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez.

(4) Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi hakkında bu madde ve Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

(5) Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verirse, bu kararın yerine getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır.

(6) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir.

(7) Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer koruma tedbirlerine başvurulabilir.

(8) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir.”

¹³² RG: 5 Mayıs 2016 / 29703.

- b) Türkiye, bir kişiyi “*düşünce suçu veya siyasî ya da askeri suç niteliğinde*” bir suç sebebiyle iade edemez.
- c) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına olarak işlenmiş bir suç sebebiyle Türkiye’den başka bir devlete iade edilemez.
- ç) Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç sebebiyle kişi bir başka devlete iade edilemez
- d) Zamanaşımına veya affa uğramış bir suç sebebiyle kişi bir başka devlete iade edilemez.
- e) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, **vatandaş** suç sebebiyle bir başka devlete **iade edilemez**.
- f) Kişinin, talep eden devlete iadesi hâlinde, ırkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle soruşturulacağına ya da kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muamele-ye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez.
- g) İade talebinin hukuken kabul edilebilir olup olmadığına asliye ceza mahkemesi değil, ağır ceza mahkemesi karar verecektir ve bu karara karşı itiraz değil, temyiz kanun yoluna başvurulabilir.
- ğ) Mahkeme iade talebinin hukuken kabul edilebilir olduğuna karar verse bile, bu kararın yerine getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır.
- h) Mahkeme, iade talebinin hukuken kabul edilebilir olduğuna karar verdiği takdirde, ayrıca iadesi talep edilen kişinin CMK hükümlerine göre tutuklanmasına veya hakkında adli kontrol gibi diğer koruma tedbirlerine karar verebilir.
- ı) İade edilen kişi, ancak iade kararına dayanak teşkil eden suçtan dolayı yargılanabilir ve cezalandırılabilir.

TCK’nın iadeye ilişkin bu hükümleri *genel ve tamamlayıcı nitelikteydi*. Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerde iadeye ilişkin olarak ayrıntılı hükümler yer almaktadır. Bu bakımdan, **somut olayda öncelikle iade talep eden veya iade talebinde bulunulan devlet ile Türkiye arasındaki sözleşme hükümlerini dikkate almak gerekir**. Şayet sözleşmede farklı bir hüküm bulunuyorsa, kanun hükümlerinin uygulamasından sarfınazar edip, sözleşme hükümlerine göre uygulama yapmak gerekir.

TCK’nın söz konusu maddesinin yürürlükten kaldırılması dolayısıyla, iadeyle bağlantılı olarak, bundan böyle **6706 sayılı Kanun hükümlerini** dikkate almak gerekir. Söz konusu Kanunda iadeye ilişkin hükümler, 10 ilâ 22. maddelerde düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanunda iadeye ilişkin olarak, aşağıdaki prensipler sıralanmıştır:

a) Türkiye’den iade talebinde bulunulması halinde, iade sebebini oluşturan fiilin Türk kanunlarına göre de suç oluşturmamasının yanı sıra, her iki ülke kanununa göre “üst sınırı bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren” suç olması ya da hüküm verilmiş ise, “hükmolunan cezanın en az dört ay hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerekir” (m. 10, f. 2).

Öncelikle belirtilmelidir ki, suçun cezasına ilişkin olarak getirilen ilave hüküm doğru olmamıştır. Bu konuda bütün iade anlaşmalarında özel hüküm bulunmadır. Bu özel hükümler karşısında, 6706 sayılı Kanunun söz konusu hükmünün haşiv kabilinden bir hüküm olduğunu kabul etmek gerekir. Zira, pek çok iade anlaşmasında bu ölçüden farklı ölçü kabul edilmiştir. Bu durumda, Kanunun söz konusu hükmünün uygulanabilirliğinden söz etmek mümkün olmayacaktır.

b) Maddenin dördüncü fıkrasında, Türkiye’den başka bir devlete iade halinde iadede hususilik kuralı düzenlenmiştir. Bu hüküm doğru olmamıştır. Türk hukuku bakımından yaptığımız bir kanuni düzenlemede, iade talebi kabul edilen devlete yönelik sınırlayıcı bir hüküm vazedilemeyeceği, malumun ilamıdır. Esasında bütün iade anlaşmalarında iadede hususilik kuralına yer verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu hüküm de haşiv kabilinden bir hükümdür.

c) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, **vatandaş** suç sebebiyle bir başka devlete **iade edilemez** (m. 11, f. 1, bent a).

ç) Kişinin, talep eden devlete iadesi hâlinde, ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle soruşturma veya kovuşturmayla maruz bırakılacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez (m. 11, f. 1, bent b).

d) Türkiye, bir kişiyi “*düşünce suçu, siyasî suç veya siyasi suçla bağlantılı bir suç niteliğinde*” ya da “*sırf askerî suç niteliğinde*” bir suç sebebiyle iade edemez (m. 11, f. 1, bent c, alt bent 1 ve 2). Ancak, “Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, siyasî suç olarak kabul edilmez” (m. 11, f. 2).

e) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına olarak işlenmiş bir suç sebebiyle Türkiye’den başka bir devlete iade edilemez (m. 11, f. 1, bent c, alt bent 3).

f) Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç sebebiyle kişi bir başka devlete iade edilemez (m. 11, f. 1, bent c, alt bent 4).

g) Zamanaşımına veya affa uğramış bir suç sebebiyle kişi bir başka devlete iade edilemez (m. 11, f. 1, bent c, alt bent 5).

ğ) İadesi talep edilen kişi, talebin sebebini oluşturan fiil nedeniyle daha önce Türkiye’de yargılanmış ve hakkında beraat veya mahkûmiyet kararı verilmiş ise, iade edilemez (m. 11, f. 1, bent ç).

h) İade talep eden devlet kanunlarına göre, talebin sebebini oluşturan suçun, **ölüm cezası** veya insan onuru ile bağdaşmayan bir ceza **ile cezalandırılmayı gerektiren** bir suç olması halinde, iade talebi kabul edilemez (m. 11, f. 1, bent d).

ı) İade talebinin hukuken kabul edilebilir olup olmadığına ağır ceza mahkemesi karar verecektir (m. 15, f. 1; m. 19, f. 1) ve bu karara karşı temyiz kanun yoluna başvurulabilir (m. 18, f. 4).

i) Mahkeme iade talebinin hukuken kabul edilebilir olduğuna karar verse bile, bu kararın yerine getirilip getirilmemesi, **“Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı”na** bağlıdır (m. 19, f. 1).

j) Mahkeme iadesi talep edilen kişinin CMK hükümlerine göre tutuklanmasına veya hakkında adli kontrol gibi diğer koruma tedbirlerine karar verebilir (m. 16).

k) *“Kişi, iadeye rıza göstermesi hâlinde normal iade usulü uygulanmadan talep eden devlete iade edilebilir”* (m. 17, f. 1): **Rızaya dayalı iade**¹³³. Bu düzenlemede, *Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi*’ne Ek Üçüncü Protokol hükümleri dikkate alınmıştır.

l) Türkiye tarafından bir başka devletten iade talebinde bulunulabilmesi için, iade sebebini oluşturan fiilin “üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren” suç olması ya da hüküm verilmiş ise, “hükmolunan hapis cezasının en az dört ay olması gerekir” (m. 22, f. 2).

Yine belirtilmelidir ki, suçun cezasına ilişkin olarak Kanunla getirilen bu ilave hüküm doğru olmamıştır. Bu konuda bütün iade anlaşmalarında özel hüküm bulunmaktadır. Bu özel hükümler karşısında, 6706 sayılı Kanunun söz konusu hükmünün haşiv kabilinden bir hüküm olduğunu kabul etmek gerekir. Zira, pek çok iade anlaşmasında bu ölçüden farklı ölçüler kabul edilmiştir. Bu durumda, Kanunun söz konusu hükmünün uygulanabilirliğinden söz etmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca işaret etmek gerekir ki, soruşturma ve kovuşturma amaçlı olarak iade bağlamında ceza miktarı ile ilgili olarak getirilen bu ölçünün sadece Türk kanunlarına göre tayini doğru olmamıştır. Zira bu düzenleme, Türkiye’nin taraf olduğu bütün iade anlaşmalarında yer alan hükümlerle çelişkilidir. Bu bağ-

¹³³ Ayrıntılı bilgi için bkz. BAYTEMİR KONTACI, Burcu: *Suçluların Geri Verilmesinde Yeni Arayışlar: Geri Vermede Basitleştirilmiş Usul*, in: Dr.Dr.h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Editörler: F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoglu, A. Sözüer, F. Turhan, Ankara, Mayıs 2018, sh. 1097 vd.

lamda, söz konusu kanun hükmünün uygulanabilirliğinin olmadığını belirtmek gerekir.

m) Türkiye tarafından bir başka devletten iade talebinde bulunulabilmesi için, şüpheli, sanık veya hükümlü “*hakkında yakalama emri veya tutuklama kararı veril*”miş olması gerekir (m. 22, f. 1)

n) Söz konusu Kanunda, Türkiye tarafından şüpheli, sanık veya hükümlünün bulunduğu ülke devletinden iadesinin talep edilmesinde “**Türkiye’nin millî güvenliğinin veya uluslararası ilişkilerinin zarar görme ihtimalinin bulunması**” halinde iade talebinden sarfınazar edilebilecektir (m. 22, f. 3, bent c). Herhangi bir hukuki izahı olmayan bu hükmün Kanuna derci, Kanun koyucunun “abesle işigali” olarak değerlendirilmiştir.

B. Kaynaklar Arasındaki İlişki

Öncelikle belirtmek gerekir ki; SİDAS’ın 28. maddesine göre, **söz konusu Sözleşmeyi onaylayan devletler arasında daha önceden yapılmış olan iade hukukuna ilişkin anlaşmalar yürürlükten kaldırılmıştır**¹³⁴. Daha önceden yapılmış anlaşmaların yürürlükten kalkabilmesi için, SİDAS’ın her iki devlet bakımından onaylanıp yürürlüğe girmiş olması gerekir. Yürürlükten kaldırılan hükümler, anlaşmaların iade hukukuna ilişkin hükümleridir. Yoksa örneğin adli yardıma ilişkin hükümleri de içeren bir iade anlaşması bütün olarak yürürlükten kalkmaz; adli yardıma ilişkin anlaşma hükümleri yürürlükte kalmaya devam eder.

SİDAS, aynı zamanda, Sözleşmeye taraf devletler arasında iade hukukuna ilişkin olarak yapılacak anlaşmaların alanını daraltmaktadır. Buna göre, SİDAS’a taraf devletler sadece bu Sözleşmenin hükümlerini tamamlayan veya bu Sözleşmenin taşıdığı kuralların uygulanmasını kolaylaştırmak üzere iki veya çok taraflı iade anlaşmaları yapabilirler (m. 28, f. 2).

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, iade kurumuna ilişkin olarak taraf olunan milletlerarası anlaşmalarla, kanunlardaki hükümlerin birbirlerini tamamlaması gerekir.

İade hukukuna ilişkin anlaşma hükümleri ile iç hukuk hükümleri arasında bir çelişki var ise; anlaşma hükümleri kendi uygulama alanı bakımından iç hukuk hükümlerinin uygulama alanını daraltmış olur. Kanunlardaki düzenlemelerle çelişen anlaşma hükümleri, anlaşma yürürlükte kaldığı sürece, iade kurumuna ilişkin kanun hükümlerinin, anlaşmanın tarafı devletlerle olan ilişkiler bakımından uygulama kabiliyetini ortadan kaldırır¹³⁵. Anlaşma hükümleri iade hukukuna ilişkin iç hukuktaki kanuni düzenlemelere nazaran özel hüküm niteliğindedir.

¹³⁴ Bu hususta yukarıdaki anlaşmalar listesine bakılmalıdır.

¹³⁵ DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 514.

Bu nedenle, iç hukuktaki kanun hükümlerinden önce uygulanmaları gerekir.^{136, 137}

Kanunlardaki iade hukukuna ilişkin düzenlemelerde yapılan bir değişiklik, bir anlaşmada bulunan hükümlere aykırı bir düzenleme getirilirse; bu değişiklikler, anlaşmanın tarafı devletlerle olan ilişkilerde etkili olmayacaktır. İç hukuk düzenlemeleri anlaşmalara göre genel hüküm niteliğindedir. Genel hükümlerde yapılan bir değişiklik kural olarak özel hükümlere etki yapmaz¹³⁸.

Bir başka sorun ise, iade anlaşmalarında bazı konularda taraf devletlerin iç hukuk düzenlemelerine yollamada bulunulması halinde ortaya çıkmaktadır. Anlaşmalarda yollama yapılan iç hukuk düzenlemelerinde sonradan değişiklik yapılması halinde, sorun nasıl çözümlenecektir? İç hukuk düzenlemelerinde yapılan değişikliklerle anlaşmaların uygulama alanı da etkilenebilmektedir. Örneğin bir anlaşmada, iadesi mümkün olan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmayan suçlar ya da bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını gerektiren suçlar olması gerektiği hususunda ceza kanunlarına yollamada bulunulabilir. Anlaşmanın yapıldığı sırada ceza kanunlarında bir suç şikayete bağlı iken, daha sonra yapılan değişiklikte re'sen takip edilebilir suç haline getirilebilir. Yine anlaşmanın yapıldığı sırada bir suçun karşılığında kanunda bir yıl süreyle hapis cezası öngörülmüş iken, yapılan değişiklikte hapis cezasının süresi altı aya indirilmiş olabilir. Bu durumlarda, iade istemi karşısında hangi kanunun esas alınacağı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Bazı yazarlar anlaşmanın yapıldığı andaki kanun hükümlerine göre sorunun çözümlenmesini ileri sürerler. Diğer bir kısım yazarlara göre ise, anlaşmanın uygulanmasında esas alınacak kanun, iade istemi hakkında karar verileceği andaki kanundur¹³⁹.

Kanaatimizce, bu durumda sorunu maddi ceza hukukuna ilişkin hükümlerin zaman bakımından uygulama kurallarına (TCK, m. 7) göre çözmek gerekir. Buna göre, *kural* olarak iade talebi hakkında, bu talebin sebebini oluşturan *suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan kanuna* göre karar verilmelidir. Ancak, lehe kanunlar geçmişe etkili olarak yürürlüğe gireceğinden; yeni kanun, iadesi istenen kişi bakımından daha lehte sonuçlar doğuruyorsa, geçmişe yürürlü olarak uygulanmalıdır.

¹³⁶ DURAN, sh. 595; ÖZGEN, sh. 16.

¹³⁷ Anlaşmaların iç hukuk hükümlerine önceliği kuralı, 1.7.1980 tarihli Avusturya İade Kanununda açıkça belirtilmiştir (m. 2). 6706 sayılı Kanunda bu hususa özgü hüküm bulunmamasını önemli bir eksiklik olarak değerlendirmekteyiz.

¹³⁸ ÖZGEN, sh. 17; DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 515.

¹³⁹ Bu konudaki görüşler için bkz. ÖZGEN, sh. 14; İÇEL, sh. 706; DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 515.

Bu durum karşısında yukarıda belirttiğimiz ihtimallerin çözümü şöyle olacaktır:

Birinci ihtimale göre, anlaşmada soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlar, iade kapsamı dışında tutulmuştur.

İşlendiği sırada şikayete bağlı olan suç sonradan yapılan kanun değişikliği ile re'sen takip edilebilen suç haline gelmiştir. Bu suçtan dolayı iadesi istenen kişi önceki kanuna göre iade edilmezken, yeni kanuna göre iade edilebilecektir. Yeni kanun sonuç itibarıyla aleyhe bir durum yaratmaktadır. Bu durumda sorun, suçun işlendiği andaki kanuna göre çözümlenmelidir.

İkinci ihtimale göre ise, anlaşmada örneğin bir yıldan az süreyle hapis cezasını gerektiren suçlar, iade kapsamı dışında bırakılmıştır. İşlendiği sırada yürürlükte olan kanunda suçun karşılığı olarak bir yıl hapis cezası öngörülmüşken; bilahare yapılan kanun değişikliği ile suçun cezası altı ay olarak belirlenmiştir. İşlenen suçtan dolayı, değişiklikten önceki kanuna göre iade mümkünken; kanunun yeni düzenlemesine göre mümkün değildir. Yeni kanun kişi açısından daha lehe bir durum yarattığı için, iade talebi hakkında yeni kanuna göre karar verilmelidir.

IV. İadenin Koşulları

Birinci koşul: İade talebinin sebebini oluşturan fiilin her iki devlet kanunlarına göre suç teşkil etmesi gerekir.

İade talebine neden olarak gösterilen fiilin her iki devlet kanununa göre suç teşkil etmesi gerekir. “*Çifte suçluluk prensibi*”¹⁴⁰ veya “*karşılıklı cezayı müstelzim olma*”¹⁴¹ diye adlandırılan bu kurala, bütün iade anlaşmalarında, dolayısı ile de olsa, yer verilmiştir. SİDAS’nin 2. maddesinin birinci fıkrasına göre, “*gerek iadeyi talebeden tarafın ve gerek kendisinden iade talep edilen tarafın kanunlarınca ... cezayı mucip fiiller*” dolayısıyla iade yoluna gidilebilir.

6706 sayılı Kanunda da, ister Türkiye’den ister Türkiye tarafından iade talebinde bulunulmuş olsun, iade talebinin sebebini oluşturan fiilin iade talep eden devlet kanunlarının yanı sıra “*Türk kanunlarına göre*” de suç teşkil etmesi şartı aranmıştır (m. 10, f. 2; m. 22, f. 2).

Ayrıca belirtmek gerekir ki, iade talebinin sebebini oluşturan fiilin her iki devlet kanununda aynı ad altında suç olarak tanımlanması gerekmez.

İkinci koşul: İade talebinin sebebini oluşturan suçun belirli bir ağırlıkta olması gerekir.

İade, devletler arasında bir adli yardımlaşma kurumu olduğundan iki devlet arasında diplomatik yolla ilişki kurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenlerle ia-

¹⁴⁰ MERAY, sh. 433; ÖZGEN, sh. 38.

¹⁴¹ ÖZGEN, sh. 38.

deye neden olabilecek suçların belirli bir ağırlık derecesine ulaşması gerekli görülmektedir.

Bu bakımdan kabahatler, iade kapsamı dışında tutulmuştur.

Gerek Türkiye'nin taraf olduğu iade anlaşmalarında gerek 6706 sayılı Kanunda iadeye neden olabilecek suçlar bakımından kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında bir ayırım yapılmamıştır¹⁴².

İadeye neden olan suçların belirlenmesi bakımından anlaşmalarda iki sistemin benimsendiği gözlemlenmektedir. Bunlardan birisi, suçları sayma sistemi; diğeri ise, asgari ceza sınırını belirleme sistemidir.

Suçları sayma sisteminde iadeye neden olabilecek suçlar teker teker belirtilmiştir. Ancak bu sistem, kanunlar arasındaki terim farklılıklarının ortaya çıkardığı uyumsuzluklar dolayısıyla terk edilmeye yüz tutmuştur. Ancak belirtilmek gerekir ki, 1980 yılında yürürlüğe giren Türkiye – ABD İade Anlaşmasında asgari ceza sınırını belirlenmenin (m. 2) yanı sıra, iade kapsamına giren belirli suçlar sayılmıştır (Ek Liste).

Asgari ceza sınırını belirleme sistemine göre, bir suçun kanuni tanımındaki cezanın belirli bir sınırdan yukarı olması halinde, iadeye neden olabilecektir. Türkiye'nin taraf olduğu iade anlaşmalarında esasen bu sistem kabul edilmiştir. Söz konusu sistemde ceza sınırı, iade edilecek kişinin şüpheli veya sanık ya da mahkum olmasına göre değişmektedir:

Şüpheli veya sanığın iadesinin söz konusu olduğu hallerde, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne göre, iadeye neden olabilecek suçun “*en aşağı bir sene müddetle*” hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olması gerekir (m. 2, f. 1).

Kanunda suçun cezasının alt ve üst sınırının belirlendiği hallerde, kanımızca *üst sınırı* dikkate almak gerekir. SİDAS'ın Türkçe metninde bu konuda bir açıklık bulunmamakta ise de; Sözleşmenin İngilizce metninde “*maximum period*” (m. 2, f. 1) ibaresi yer aldığından, söz konusu en az cezanın **üst sınıra** göre belirlenmesi gerekecektir¹⁴³.

1982 yılında yürürlüğe giren Türkiye – Macaristan (m. 17/1) ve 1983 yılında yürürlüğe giren Türkiye – Suriye (m. 2/1-a) iade anlaşmalarında bu sınır bakımından kanunda öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın “azami haddi”; buna karşılık, 1980 yılında yürürlüğe giren Türkiye – ABD iade anlaşmasında ise (m. 2/1-b) “asgari haddi” esas alınmıştır.

¹⁴² 1980 tarihli Avusturya İade Kanunu'nda (m. 11) ancak kasten işlenebilen suçlar, iade kapsamında mütalaa edilmiştir.

¹⁴³ EREM, sh. 215.

Bu sınırın belirlenmesinde, **hem iade talep eden hem de talep edilen devlet kanunlarının** göz önünde bulundurulması gerekir.

Hükümlünün iadesinin söz konusu olduğu hallerde, SİDAS'a göre, mahkemece hükümlü olan cezanın asgari dört ay süreli hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerekir (m. 2, f. 1)¹⁴⁴. Türkiye'nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarında bu hususta farklı süreler belirlenmiştir.

Bu bağlamda bir sorunla karşılaşmaktadır: Asgari sınırın üzerinde bir cezaya hükümlülük halinde, işlenen suçun kanunda öngörülen cezasının ayrıca ilgili sözleşmede belirlenen sınırın üzerinde olup olmadığı araştırılacak mıdır? Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi bakımından sorun tartışılmıştır. *Dönmezer/Erman*'a göre, asgari sınırın üzerinde bir cezaya hükümlülük halinde dahi, suçun karşılığında iade isteminde bulunan devlet kanuna göre en az bir yıl süreli hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmelidir¹⁴⁵. Buna karşılık, *Erem*'e göre ise, asgari bir yıl hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suçtan dolayı en az dört ay süreyle cezaya mahkumiyet koşulunu aramak, sözleşmeye onda bulunmayan bir hükmü eklemek anlamına gelir¹⁴⁶. Kanaatimizce, asgari sınırın üzerinde hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyet halinde, iade talebinin sebebini oluşturan suçun karşılığında kanunda öngörülen asgari ceza sınırının araştırılmaması gerekir.

İadesi talep edilen kişi tarafından işlenen veya işlendiği iddia edilen birden fazla suç olabilir. Bu durumda kişi, ağırlık bakımından iade anlaşmalarında belirlenen kapsama girmeyen suçlardan dolayı da iade edilebilmektedir (Bkz. SİDAS, m. 2, f. 2). Aynı yönde hükme 6706 s. Kanunda da yer verilmiştir (m. 10, f. 2, üçüncü cümle).

Suçta teşebbüs ve iştirak durumunda da iade mümkün olacaktır. Bunun için iade anlaşmalarında açık hüküm bulunmasına gerek yoktur. Ancak, teşebbüs ve iştirak durumlarında iadenin mümkün olabilmesi için, iade talebinin sebebini oluşturan suç hakkında anlaşmalarda gerek şüpheli veya sanık olma durumuna ilişkin ve gerekse hükümlülük durumuna ilişkin belirlenen en az ceza koşulunun gerçekleşmesi gerekir.

Yukarıda izah ettiğimiz üzere, Türkiye'nin taraf olduğu her bir iade anlaşmasında iade kapsamına giren suçlara ilişkin sınırların belirlenmiş olmasına rağmen, 6706 sayılı Kanunda iade talebine sebep teşkil eden suçun ağırlığı ile ilgili olarak ceza miktarları itibarıyla ölçülere yer verilmiştir:

a) Türkiye'den iade talebinde bulunulması halinde, iade sebebini oluşturan fiilin Türk kanunlarına göre de suç oluşturmamasının yanı sıra, her iki ülke kanununa

¹⁴⁴ Sözleşmenin Resmi Gazetede yayımlanan Türkçe metninde “*bir cezaya mahkumiyet hükmü veya bir mevkufiyet kararı*” ibaresi yer almaktadır. Söz konusu “*mevkufiyet kararı*” ibaresi **güvenlik tedbiri** olarak anlaşılmalıdır. Çünkü Sözleşmenin İngilizce metninde “**detention order**” ibaresi kullanılmıştır.

¹⁴⁵ DÖNMEZER-ERMAN III, sh. 520.

¹⁴⁶ EREM, sh. 216.

göre “üst sınırı bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren” suç olması ya da hüküm verilmiş ise, “hükmolunan cezanın en az dört ay hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerekir” (m. 10, f. 2).

b) Türkiye tarafından bir başka devletten iade talebinde bulunulabilmesi için, iade sebebini oluşturan fiilin “üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren” suç olması ya da hüküm verilmiş ise, “hükmolunan hapis cezasının en az dört ay olması gerekir” (m. 22, f. 2).

Bu hükümlerin eleştirisi için yukarıdaki açıklamalarımıza işaret etmekle iktifa etmekteyiz.

Üçüncü koşul: İade talebinin sebebini oluşturan suçun takip edilebilir olması gerekir.

İadeye neden olabilecek suçun gerek iade talebinde bulunan ve gerekse talepte bulunulan devlet kanunlarına göre dava ve ceza zamanaşımına uğramaması gerekir (SİDAS, m. 10; SİDAS’a Ek Dördüncü Protokol, m. 1; 6706 s. Kanun, m. 11, f. 1, bent c, alt bent 5). Zamanaşımı bakımından göz önünde bulundurulacak husus sadece süreler olmamalıdır; zamanaşımını kesen ve durduran sebepler gibi diğer hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yargı organlarınca yapılmış olsalar bile iadeye ilişkin işlemlerin zamanaşımını kesmeyeceği kabul edilmiştir¹⁴⁷. Buna göre iadesi istenen kişinin yargı organları önünde sorguya çekilmesi veya iade amacıyla tutuklanması zamanaşımını kesmeyecektir¹⁴⁸.

Zamanaşımının ne zaman dolmuş sayılacağı da bir sorun teşkil etmektedir. Bazı iade anlaşmalarında bu hususta açık hüküm bulunmaktadır. Anlaşmalarda açık hüküm bulunmayan hallerde, talepte bulunulan devletçe iade talebinin resmen alındığı ana göre zamanaşımının dolup dolmadığının belirlenmesi daha uygun olur. Çünkü iade talebi ile kişinin teslimi arasında zamanaşımı süresinin dolması mümkündür. Ayrıca zamanaşımının dolmasını sağlamak amacıyla teslim geciktirilebilir¹⁴⁹.

İade talebinde bulunan devlette iade talebinin nedenini oluşturan suç soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı bir suç ise ve henüz şikayet de yapılmamışsa iade talebi kabul edilmeyecektir. Buna karşılık, iade talebinde bulunulan devlet kanunlarına göre şikayete bağlı olsa bile, talepte bulunan devlet kanunlarına göre re’sen takip edilebilen suç nedeniyle iade yoluna gidilmelidir¹⁵⁰.

¹⁴⁷ EREM, sh. 229.

¹⁴⁸ DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 522.

¹⁴⁹ EREM, sh. 229.

¹⁵⁰ ÖZGEN, sh. 41.

Dördüncü koşul: İade talebinin sebebini oluşturan suçun affa uğramamış olması gerekir.

İade talebinin sebebini oluşturan suçun talep eden devlette affa uğramış olması halinde iade yoluna gidilemez. Ancak, kısmen affa uğrama durumunda, af kapsamı dışında bırakılan ceza miktarı genel koşullara göre iadeye elverişli ise yine iade mümkün olmalıdır.

Buna karşılık, iade talebinde bulunulan devlette bir af ilan edilmesi, nitelik itibarıyla af kapsamına girmekle birlikte, bu devletin yargılamaya yetkili olmadığı suçlar bakımından iadeye engel olmamalıdır¹⁵¹. SİDAS’a 2. Ek Protokolün 4. maddesinde bu görüşe uygun bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre iade talebinin sebebini oluşturan suç talepte bulunulan devlette affa uğramışsa, ancak söz konusu devletin kanunlarına göre bu suçtan dolayı failini yargılama yetkisine sahip olması halinde talep kabul olunmayacaktır.

6706 sayılı Kanunda iade talebinin sebebini oluşturan suçun talep eden devlette mi yoksa talep edilen devlette mi affa uğramaması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir (m. 11, f. 1, bent c, alt bent 5). Bu durumda söz konusu hükmü, iade talebinin kabulü için suçun her iki devlette de affa uğramamış olması şeklinde anlamak gerekir.

Türkiye’nin taraf olduğu bazı iade anlaşmalarında sadece genel af kapsamına giren suçların iadeye engel olacağı hüküm altına alınmıştır (Örneğin, Romanya, Ürdün, Macaristan ve Tunus ile yapılan anlaşmalar). Buna karşılık, ABD (1980) ile yapılan anlaşmada hem genel, hem de özel af öngörülmüştür. Yugoslavya (1974) ve Bulgaristan (1977) ile yapılan anlaşmalarda genel özel ayırımı yapılmadan sadece “af” kavramı kullanılmıştır.

V. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Karşılığı Olarak Öngörülen Yaptırımın Niteliği Dolayısıyla Geriverme Sorunu

A. Yaptırım Olarak Güvenlik Tedbiri Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu

SİDAS’ın 2. maddesine göre iadeyi gerekli kılan suçlara ilişkin olarak kanunlarda öngörülen yaptırımın hürriyeti bağlayıcı ceza veya güvenlik tedbiri olması mümkündür. Ayrıca sözleşme çeşitli devletlerde anlam bakımından farklılık göstermesi nedeniyle güvenlik tedbirlerinin tanımını vermiştir. Buna göre: “*İşbu sözleşme anlamında ‘emniyet tedbirleri’ tabiri, ceza mahkemesi kararı ile bir cezayı itmam veya onun yerine geçmek üzere emredilen hürriyeti tahdit edici her türlü tedbirlerdir.*” (m. 25).

Kanaatimizce, bir suçun karşılığında yaptırım olarak güvenlik tedbiri öngörülemez. Ancak, bir suç sebebiyle güvenlik tedbirine hükmedilebilir. Bu itibarla, sadece hükümlünün iadesi bakımından bu bağlamda bir sorunla karşı karşıya

¹⁵¹ Benzer bir görüş EREM, sh. 230.

gelinebileceği düşünülebilirse de; kanaatimizce, bu durumun iade hukuku bakımından sorun teşkil eden bir yönünü mevcut değildir.

B. Adli Para Cezası Gibi Mali Nitelikte Yaptırımı Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu

SİDAS’da sadece mali nitelikte ceza ile müeyyidelendirilmiş suçlar bakımından iadenin mümkün olup olmayacağına ilişkin açıklık bulunmamaktadır. Bu durum karşısında, sadece adli para cezasını veya mali nitelikte sair bir cezayı gerektiren suçların iade kapsamı dışında bırakıldığı sonucuna ulaşabiliriz.

Ancak 17.3.1978 tarihli “**Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 2. Protokol**”ün 1. maddesiyle taraf devletlere adli para cezası gibi sadece mali nitelikte ceza ile müeyyidelendirilmiş bulunan suçlardan dolayı da iade edebilme yetkisi tanınmıştır.

C. Ölüm Cezası ve İade Sorunu

SİDAS’ın 11. maddesine göre iade talebinde bulunan devlet yasalarına göre talebin sebebini oluşturan suç hakkında öngörülen cezanın ölüm cezası olmasına karşılık, talepte bulunan devlet yasalarında ölüm cezasının bulunmaması ya da bulunmasına rağmen genellikle uygulanmaması durumunda, talepte bulunan devletin ölüm cezasının uygulanmayacağına ilişkin olarak, talepte bulunulan devlete ancak güvence vermesi durumunda iade talebi kabul olunacaktır. Dikkat edilmelidir ki güvencenin ölüm cezasının hükmolunmayacağına ilişkin değil, söz konusu cezanın infaz edilmeyeceğine ilişkin olması yeterlidir. Ayrıca verilen güvencenin yeterli olup olmadığına takdir hakkı talepte bulunulan devlete aittir.

Türk hukuku bakımından verilmiş bir cezanın uygulanmaması kural olarak ancak kanunla sağlanabilir. Nitekim sözleşmenin 11. maddesinin görüşülmesi sırasında Türk temsilcisi, bu konuda güvence talebiyle karşılaşan Türk hükümetinin ancak somut olaya ilişkin ölüm cezasının başka bir cezaya çevrilmesini öngören bir yasa tasarısını TBMM’ne sunabileceği ihtirazı kaydında bulunmuştur.

Ancak, Türkiye de “**İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol**”ü onaylayarak, “**ölüm cezasının her durumda kaldırılması için nihai adımı atmaya karar ver**”miştir¹⁵².

Anayasanın 38'inci maddesinde, **7.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Kanunla** yapılan değişiklikle, herhangi bir istisna öngörülmezsizin “**Ölüm cezası ... verilemez.**” (f. 10) hükmüne yer verilmiştir¹⁵³.

¹⁵² Söz konusu Protokollün onaylanması **6.10.2005 tarihli ve 5409 sayılı Kanunla** uygun bulunmuştur. Protokol metni, 12 Ekim 2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵³ Birçok devlet anayasasında ölüm cezasının kaldırıldığına dair hükümlere yer verilmiştir. (Almanya, m. 102; İspanya, m. 15; Avusturya, m. 85).

Anayasada yapılan bu değişiklikten sonra, kanunlarda yer alan çeşitli suçlar karşılığında öngörülen ölüm cezası, **14.7.2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunla**, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülmüştür. Yeni TCK'da da ölüm cezasına yer verilmemiştir.

Bu düzenlemeler karşısında Türkiye'nin SİDAS'ın imzalanması sırasında ölüm cezasıyla ilgili olarak ileri sürdüğü çekincenin (ihtirazi kaydın) artık bir anlamı kalmamıştır.

Yeni TCK'nın 18. maddesinde, iade talep eden devlet kanunlarında talebin sebebini oluşturan suçun karşılığında ölüm cezası öngörülmüş olması, bir iade engeli olarak gösterilmemiş iken; **6706 sayılı Kanun, iade talep eden devlet kanunlarına göre, talebin sebebini oluşturan suçun, ölüm cezası veya insan onuru ile bağdaşmayan bir ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir suç olması halinde, iade talebinin kabul edilemeyeceğini amirdir** (m. 11, f. 1, bent d). Ancak söz konusu Kanuna göre, SİDAS gibi, talep eden devletin ölüm cezasının infaz edilmeyeceği konusunda Türkiye'ye “yeterli teminat” (?) vermesi halinde, bu suç sebebiyle de iade yoluna gidilebilecektir (m. 11, f. 3).

İade ve sınır dışı etme (geri gönderme) yasağı (non refoulement ilkesi) gereğince, bir yabancı, iade veya sınır dışı edildiğinde gönderileceği ülkede işkenceye, insanlık dışı veya haysiyet veya onur kırıcı muameleye maruz kalma riski mevcut ise, bu ülkeye gönderilemez¹⁵⁴.

İade ve sınır dışı etme (geri gönderme) yasağı (non refoulement ilkesi), Türkiye'nin 29.8.1961 tarihli ve 359 sayılı Kanun ile onaylayarak taraf olduğu Birleşmiş Milletler “**Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme**”de¹⁵⁵ hüküm altına alınmıştır. Söz konusu Sözleşmenin “*Sınır dışı veya iade etme yasağı*” başlıklı 33. maddesine göre,

“1. Hiçbir Âkîd Devlet bir mülteciyi, ırkı, dini, vatandaşlığı, muayyen bir içtimai zümreye mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayat ve hürriyetinin tehdit edileceği ülkelerin hudutlarından her ne şekilde olursa olsun sınır dışı veya iade edemez.

*2. Bununla beraber, bulunduğu memleketin emniyeti için tehlikeli sayılması hususunda ciddi sebepler mevcut olan veya bilhassa vahim bir cürümden dolayı katılmış bir hükümle mahkûm olduğu için mezkûr memleket topluluğu için bir tehlike teşkil eden bir mülteci işbu hükümden istifadeyi talep edemez.”*¹⁵⁶

¹⁵⁴ EKŞİ, Nuray: *Mahkeme Kararları Işığında Suçluların İltica Sistemi Dışında Bırakılması*, İstanbul, Kasım 2017, sh. 29.

¹⁵⁵ Söz konusu Sözleşme metni ile bu Sözleşmenin onaylanmasına ilişkin 29.8.1961 tarihli ve 359 sayılı Kanun, 5 Eylül 1961 tarih ve 10898 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁵⁶ Ayrıca bkz.:

a) *Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi* (Paris, 13.12.1957), m. 3, f. 2.

Keza, 4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı **Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun** “Geri gönderme yasağı” başlıklı 4. maddesine göre;

“Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamalarında da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin işkence ve insanlık dışı muamele yasağını düzenleyen 3. maddesi hükmüne istinaden, bir yabancıнын, başka bir ülkeye gönderildiği takdirde işkence, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalma tehlikesi mevcut ise, geri gönderilmesini bir hak ihlali olarak değerlendirmektedir¹⁵⁷. Hatta Anayasa Mahkemesinin de çeşitli bireysel başvurular çerçevesinde benzer kararlar verdiği görülmektedir¹⁵⁸.

VI. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Niteliği Dolayısıyla İade Sorunu

A. Siyasi Suçlar Nedeniyle İade Sorunu

İadeye neden olabilen suçların en önemli istisnasını siyasi suçlar teşkil etmektedir. Kapsamı bakımından sözleşme hükümlerinde ve uygulamada farklılıklar bulunmasına rağmen, siyasi suç nedeniyle iade yoluna gidilemeyeceği, milletlerarası hukukta kural halini almış bulunmaktadır¹⁵⁹.

Siyasi suçlar nedeniyle iade yoluna gidilmemesinin birtakım hukuki dayanakları vardır. Bunlardan birincisi *sığınma hakkı*¹⁶⁰.

Bir devlet yasalarına göre suç teşkil eden fiil, diğer bir devlet yetkililerine göre övgüye layık, haklı bir fiil olarak kabul edilir¹⁶¹.

Bu konuda ileri sürülen diğer bir gerekçe de siyasi suçlular iade edildiklerinde, iade olunan ülkede objektif ve tarafsız olarak yargılanacakları konusunda iade

b) *İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi* (New York, 10 Şubat 1984), m. 3.

c) *Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi* (13.12.2000, Palermo), m. 16, f. 14.

ç) *Medenî ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme* (Birleşmiş Milletler, 15.08.2000, New York), m. 7

d) *İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme* (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 4 Kasım 1950), m. 3.

¹⁵⁷ Bu kararlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. EKŞİ, sh. 35 vd.

¹⁵⁸ Bu kararlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. EKŞİ, sh. 38, dn. 103.

¹⁵⁹ Bu konudaki fikirler için bkz. BAYRAKTAR, Köksal: *Siyasal Suç*, İstanbul, 1982, sh. 196; ÖZGEN, sh. 84, 85; ARMAOĞLU, sh. 1601, 1602.

¹⁶⁰ BAYRAKTAR, sh. 196.

¹⁶¹ BAYRAKTAR, sh. 196.

eden ülke de bir kanaatin oluşamamasıdır. Gerçekten siyasi suç faillerinin hasımlarının bulunduğu devlet yargıçlarınca yapılacak yargılamalarının tarafsız olacağı kabul olunamamaktadır¹⁶².

Belirtmek gerekir ki, “*siyasi suç*” kavramı, bir maddi ceza hukuku kavramı değildir. Ancak, infaz hukuku uygulamasında, siyasi amaç veya saiklerle suç işleyen kişileri ifade zımında “*siyasi suçlu*” kategorisinden söz edilmektedir. Keza, “*siyasi suç*” kavramı, milletlerarası sözleşmelerde ve iade uygulamasında kullanılan bir kavramdır.

İade uygulaması bakımından siyasi suçlarla ilgili olarak, “*tam siyasi suç*”, “*nispi siyasi suç*”, “*bağlantılı siyasi suç*”, “*siyasi suç benzeri suç*” gibi kavramlar kullanılmaktadır¹⁶³.

Maddi ceza hukuku kavramı olmayan “*siyasi suç*” kavramının genel kabul görmüş bir tanımı mevcut değildir. Bu nedenle, açıklamalarımızda, bir suça siyasi suç vasfını kazandıran belirli hususlara işaret etmekle yetineceğiz.

Siyasi suçlar, *devletin varlığına, benimsediği siyasal düzenin işleyişine karşı işlenen ve fakat, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali niteliği taşımayan suçlar* olmalıdır.

Keza, esasen suç teşkil eden bir fiilin siyasi bir saik veya amaçla işlenmesi halinde de siyasi suçtan söz edilmektedir¹⁶⁴.

Gerek SİDAS’da (m. 3, f. 1) ve gerekse Türkiye’nin taraf olduğu iade anlaşmalarında siyasi suçlardan ve buna “*murtabit*” (bağlantılı) suçlardan dolayı iade yoluna gidilemeyeceği belirtilmiştir.

SİDAS’ın 3. maddesinin birinci fıkrasında siyasi suçlar nedeniyle iade yoluna gidilemeyeceğine ilişkin kural belirtildikten sonra; dördüncü fıkrasında, taraf devletlerin onaylamış oldukları ve onaylayacakları diğer çok taraflı sözleşmelerle iade hukuku bakımından siyasi suç kavramının alanının daraltılabileceği de ifade edilmiştir.

6706 sayılı Kanuna göre, Türkiye, bir kişiyi “*düşünce suçu, siyasî suç veya siyasi suçla bağlantılı bir suç niteliğinde*” ya da “*sırf askerî suç niteliğinde*” bir suç sebebiyle iade edemez (m. 11, f. 1, bent c, alt bent 1 ve 2). Ancak, “*Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, siyasî suç olarak kabul edilmez*” (m. 11, f. 2).

6706 sayılı Kanun, iadenin istisnasını oluşturan siyasi suç kavramının kapsamını genişletmektedir. Belirtmek gerekir ki, gerek doktrinde gerek milletlerarası uygulamada, siyasi suçlar nedeniyle iade yoluna gidilmeme kuralının nispi siyasi suçlar bakımından işletilmemesi yönünde bir eğilim egemen olmaya başla-

¹⁶² DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 529; ÖZGEN, sh. 84; BAYRAKTAR, sh. 196.

¹⁶³ BAYRAKTAR, sh. 70.

¹⁶⁴ Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nde “*siyasal saiklerle işlenen suç*” ibaresi kullanılmıştır (m. 1).

mıştır. Bu çerçevede “üstünlük görüşü”ne itibar edilmektedir. Buna göre, karma siyasi suçta, meydana gelen siyasi suç ile adi suç ve bağlı siyasal suçta da araç niteliğindeki adi suç ile amaç olan siyasal suç karşılaştırıldığında üstün olan yararı ihlâl eden suça önem verilmektedir¹⁶⁵. Böyle bir fiilin adi suç özelliği ile siyasal suç özelliği, fiilin işleniş biçimi ve sonuçları açısından değerlendirilecek ve bu şekilde üstün yarar ortaya çıkarılacaktır.

SİDAS’ın görüşmeleri sırasında 3. maddedeki “böyle bir suç ile murtabit fiil” ifadesi yerine Avusturya temsilcisi tarafından “siyasi karakteri öngelir vasıfta...” denilmesi önerilmişse de, bu öneri kabul edilmemiştir¹⁶⁶. Buna dayanılarak SİDAS’ın nispi siyasal suçlar bakımından üstünlük görüşünü kabul etmediği sonucuna varılmıştır¹⁶⁷.

Siyasi suçlar nedeniyle gerivermeme kuralı, içerikleri arasında farklılıklar bulunsa da, Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarında yer almaktadır.

Yargıtay 1. CD, 1949 yılında verdiği bir kararda; “*Adi bir suçun siyasi suç mahiyetini iktisap etmesi behemehal fiilen ve maddeten siyasi bir suçun işlenmesine veya işlenmesi tasavvur edilmesine mütevakıf olmayıp, teessüs eden rejime muhalif siyasi bir telâkki besleyenlerin bu siyasi fikir ve telakkilerinden dolayı nefislerine ağır tehlikeler tevhit edecek surette haksız muamelelere ve hususi bir nezaret ve takibe maruz kalmaları, adi fiilin siyasi fiile irtibatının kabulüne esas teşkil edebileceği*” tespitinde bulunmuştur¹⁶⁸. Bu kararda Yargıtay sübjektif görüşü benimsemiştir¹⁶⁹. Keza, aynı Daire, başka bir kararında, sanıkların “*uçak kaçırma, uçak mürettebatından birini öldürme ve diğerini öldürmeye teşebbüs fiillerini ... devamlı insan hak ve hürriyetleri ile uzlaştırılmaz baskıya dayanamayarak canlarını kurtarmak...*” saikiyle işledikleri, bu saikin siyasi saik olduğu ve “*... meydana gelen cürümler(in) ise murtabit siyasi suç mahiyetini*”i taşıdığı sonucuna varmıştır¹⁷⁰.

Buna karşılık söz konusu karara (Yargıtay) C. Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine Yargıtay CGK’nun 08.03.1971 tarih ve E. 1970/490, K. 1971/65 sayılı Kararında¹⁷¹ ise, şu sonuca varılmıştır:

“Bir devletin rejimini kendi telakkilerine göre kabul etmemek, beğenmemek nazari ve afaki bakımdan siyasi bir görüş diye mütalâa edilse bile bu yüzden işlenen adam öldürmek, öldürmeye teşebbüs ederek ağır yarala-

¹⁶⁵ BAYRAKTAR, sh. 121; DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 543.

¹⁶⁶ ÖZGEN, sh. 102; BAYRAKTAR, sh. 122; dip not.

¹⁶⁷ ÖZGEN, sh. 102.

¹⁶⁸ 1. CD, 13.04.1949, 1010/687 (Karar metni için bkz. DÖNMEZER, Sulhi: *Yabancı Memleket-te İşlenen Suçlar, Siyasi Suçlar ve Nisbi Siyasi Suçlar*, İstanbul ÜHFM, 1949, sh. 763).

¹⁶⁹ DÖNMEZER, sh. 771; ÖNDER, Ayhan: *Uluslararası Şiddet, Şiddet Eylemleri*, Milliyet, 28.12.1975.

¹⁷⁰ 1. CD, 21.12.1970, 3701/3579 (RKD, 1971, 3. bölüm, sh.13).

¹⁷¹ RKD. 1971, 3. bölüm, sh. 25.

mak gibi suçların ne objektif, ne de sübjektif bakımdan siyasi ve ona murtabit suçlar olarak nitelendirilmesi mümkün görülmez, diğer bir deyimle bir rejimi mücerret rejim yönünden kabul etmemek, beğenmemek kanunî ve hukuki anlamda siyasi suç saiki sayılamaz. SSCB'deki müesses rejim dolayısıyla gelecekte kendilerine tazyikte bulunulabileceği ve takibe maruz kalabilecekleri ihtimali ... ile katil ve ağır surette yaralamak gibi suçların işlenmesi siyasi veya ona murtabit suçlardan sayılamaz”

Aynı görüş, Yargıtay 8. CD'nin 11.01.1983 tarih ve E. 1983/1, K.1983/43 sayılı Kararında¹⁷² da benimsenmiştir.

6706 sayılı Kanunda “*siyasi suç*” kavramının yanı sıra “*düşünce suçu*” kavramı da kullanılmıştır.

“Siyasi suç” gibi “düşünce suçu” kavramı da bir maddi ceza hukuku kavramı değildir¹⁷³. Bu nedenle, “düşünce suçu” kavramının tanımı yapılamamaktadır. Ancak, aşağıdaki açıklamalarımızın, düşünce açıklamasıyla suç arasındaki ilişki ile “düşünce suçu” bağlamında yapılacak olan değerlendirmelerde göz önünde bulundurulmasında fayda mülahaza etmekteyiz:

Düşünme, kendi varlığının şuurunda olan insanın, çevresindeki vakıaları, olguları algılaması ve bunlardan belli sonuçlar çıkarması sürecidir. Düşünebilmek için, insanın önce anlama ve algılama kabiliyetinin gelişmiş olması gerekir.

Düşüncenin en önemli yönü; bunun, insanın iç dünyasına hapsedilmeyip, dışa yansımasıdır. Aksi takdirde, soyut düşünmenin insana sağlayacağı bir yarardan bahsedilemez.

Düşüncenin dışa yansıma biçimlerinden biri, bunun *açıklanması*dır. Düşünmek, insan için tabîî bir hak olduğuna göre; düşündüklerini açıklamak da insanın bu tabîî hakkının vazgeçilmez sonucudur. Ancak, düşünce açıklamasının sınırsız olduğu söylenemez¹⁷⁴.

¹⁷² YKD, Şubat 1983, sh. 289.

¹⁷³ “Düşünce suçu” kavramına yönelik eleştiri için bkz. ARTUK/ÇINAR, Türk Ceza Kanunu Reformu, sh. 75; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, Dördüncü Bölüm, §2, III, 2, B.

¹⁷⁴ Özek’e göre, “düşünce, teorik, bir ölçüde soyut, belirli bir bakış açısını ve mantığını içeren, belirli konulardaki açıklamalardır. ... ‘düşünce’, belirli bir konudaki sistematik ‘tezi’ ifade eder”. Bu itibarla, “bilimsel değeri bulunmayan ... (fikrî) ürünler, ... düşünce açıklama hürriyetinin dışında kalır” (ÖZEK, Çetin: *Türk Basın Hukuku*, İstanbul, 1978, sh. 81). Bizim yukarıda düşüncenin tanımına ilişkin görüşümüze nazaran Özek’in tanımı farklılık arz etmektedir: Özek’e göre, “kişilerin şeref ve haysiyetlerine karşı saldırı niteliğindeki açıklamalar ‘düşünce kavramı’ dışında kalmaktadır” (ÖZEK, *Türk Basın Hukuku*, sh. 81). Keza, suç işlemeye tahrik, teşvik, suçu veya suçluyu övme fiilleri, “düşünce kavramının dışında kal”maktadır (ÖZEK, *Türk Basın Hukuku*, sh. 82). Bu itibarla, düşüncüyü açıklama hürriyeti sınırsızdır (ÖZEK, *Türk Basın Hukuku*, sh. 74 vd.; aynı yazar: “Devletin Korunması”, “Terörle Müca-

Düşünce açıklamak suretiyle, belli bir insanın şahsiyetine tecavüz teşkil eden açıklamalarda bulunulamaz. Kişinin muttali olduğu bir vakıya ilişkin haber verme kapsamında olsa bile, bu prensiplere riayet edilmesi gerekir.

Bir insan, inançları dolayısıyla kınanamaz. İnsanın sahip olduğu inanç, batıl bir inanç olabilir. Bir inancın batıl, yanlış ve insan için zararlı bir inanç olduğu yargısında bulunulabilir. Ancak, bu inanca mensup kişilerin kınanması cihetine gidilemez. Meğer ki esasen haksızlık ve hatta suç teşkil eden bir fiil bu batıl, yanlış inanca istinaden işlenmiş olsun.

Düşünce açıklamak suretiyle; insanlar suç işlemeye tahrik ve teşvik edilemezler; suçlar ve suçlular övülemezler; insanlar birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa davet edilemezler. Bu itibarla; inanç veya ırk bakımından ya da sosyal veya ekonomik yönden mevcut farklılıklar dolayısıyla insanların birbirlerine karşı kin ve düşmanlık beslemeye tahrik ve teşviki, düşünce açıklama hürriyeti kapsamında mütalâa edilemez¹⁷⁵.

B. Terör Eylemleri Nedeniyle İade Sorunu

Bir maddi ceza hukuku kavramı olmayan “terör”den ve “terör eylemleri”nden neyin anlaşılması gerektiği konusunda bir fikir sahibi olabilmek için, 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan **29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanun**¹⁷⁶ **Genel Gerekçesinin**¹⁷⁷ yeterli açıklıkta olduğu kanısındayız:

“Hukuk devleti esasına dayalı toplum düzenleri için en büyük tehlikeyi oluşturan terör eylemleri, kişi hak ve özgürlüklerinin kullanılması açısından bir tehdit oluşturmakta ve ayrıca, toplumun sosyal ve ekonomik bakımından gelişmesini engellemektedir.

İnsan onuruna ve buna bağlı olarak insan hak ve özgürlüklerine saygı, bireyin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, hukuk toplumunun temel prensiplerini oluşturmaktadır. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkı, insan vücudunun dokunulmazlığı ve saygınlığı hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı ve aynı zamanda düşünce özgürlüğü, düşün-

dele Yasası” ve “Bilgilenme Hakkı”, Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet, Edip F. Çelik’e Armağan, İstanbul 1995, sh. 244 vd.).

¹⁷⁵ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: İnsan Hakları (Sempozyumu, İstanbul 10 - 11 Aralık 1994), 2. bası, İstanbul 1995, *Sonuç Tebliği*, sh. 328 vd. ve ayrıca ÖZGENÇ, İzzet: *İnsan Haklarının Özüne Dönüş*, in: Yeni Türkiye, Mayıs-Haziran 1998, yıl 4, sayı 21, sh. 606 vd.; aynı yazar, *Düşünceyi Açıklama Hürriyeti ve Ceza Hukuku*, in: 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu, Diyarbakır, 22-23 Ekim 1998. sh. 180 vd.

¹⁷⁶ Söz konusu Kanun, 18 Temmuz 2006 tarihli ve 26232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷⁷ Söz konusu Genel Gerekçe metni için bkz. TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Sıra Sayısı: 1222.

ceyi özgürce açıklama ve özgürce bilgilendirilme hakkı, hukuk devleti esasına dayalı toplum düzeninin temelini oluşturan haklardır.

Terör eylemleri, bu hakların kullanılmasını tehlikeye sokmakta; hukuk devleti esasına dayalı toplum düzeninin bozulmasını, bireysel hakların ve demokratik düzenin dayanağını oluşturan temel prensiplerin ihlalini sonuçlamaktadır. Bu eylemler, halkın korku ve paniğe kapılmasına, toplumdaki siyasi, ekonomik ve sosyal yapıların büyük ölçüde zarar görmesine sebebiyet vermektedir.

Terör eylemleri bağlamında; bir örgüt faaliyeti çerçevesinde başta öldürme ve yaralama olmak üzere, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişinin çeşitli hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının engellenmesi, kişilerin ve özellikle kamusal nitelikteki malvarlıklarına zarar verme gibi suçlar **sistemli olarak** işlenmektedir. Bu suçların işlenmesi suretiyle, suç mağdurları ve bunların yakınları büyük bir eleme sevkedilmekte, bu insanların geleceğe yönelik bütün planları altüst edilmekte ve insanları hayata bağlayan temel unsurlar yok edilmektedir. Terör eylemlerine maruz kalan kişiler, maddi ve manevi bakımdan büyük zararlar görmekte ve hatta, hayatlarını kaybetmektedir.

Terör, yeni bir olgu değildir. İnsanlık tarihi kadar geçmişe sahip olan terör, bugün eskiye nazaran daha tehlikeli bir hal almıştır. Zira, günümüzde teröristler, sosyal ve ekonomik bakımdan büyük çapta tahribata sebebiyet verebilecek ve hatta, toplu ölümleri ve kitlelerin imhasını sonuçlayacak etkide silahlara sahip olabilmektedir. Günümüzde teröristler, güttükleri amaçlara ulaşabilmek için icra ettikleri fiillerin ortaya çıkarabileceği muhtemel neticeler açısından tamamen umursamaz bir duyguyla hareket etmektedirler. Günümüzde uluslararası bir yapılanmaya sahip olan teröristlerin çeşitli ülkelerde bağlantıları mevcuttur. Değişik ülkelerde lojistiği bulunan teröristler arasında uluslararası düzeyde bir iletişim ağı mevcuttur. Teknolojik gelişmişlik ve bu konudaki bilgilere ulaşma kolaylıkları, teröristlerin işini de oldukça kolaylaştırmaktadır.

Terörist eylemler, **esas itibarıyla ceza kanunlarında tanımlanmış suçları** oluşturmaktadır. Ancak, bu suçlar, gerek işlenişinde güdülen **saik** gerek **işleniş tarz ve mahiyeti** itibarıyla "terör suçu" olarak nitelendirilmektedir. **Ceza kanunlarında esas itibarıyla suç olarak tanımlanan bu fiillerin bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesiyle**, devletin ana yapısını, bu yapının dayandığı temel prensipleri değiştirmek veya yıkmak, toplumda korku ve panik yaratmak amacının güdülmüş olması durumunda, bu suç bir "terör suçu" niteliği kazanmaktadır.

"Terör" kavramı kapsamına hangi suçların girdiği konusunda bir belirsizlik mevcuttur. Bu nedenle terörle mücadeleyi konu edinen uluslararası sözleşmelerde terörle ilgili bir tanım verilmemiş, sadece terör eylemleri olarak ni-

telendirilebilecek suçlara ilişkin ayrıntılı bir liste yapılmıştır. Türkiye'nin de taraf olduğu 27 Ocak 1977 tarihli "Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi" bu konuda bir örnek olarak gösterilebilir. Bu sözleşmede, genel olarak terörizm kavramından söz edilmiştir. Esasında suç teşkil eden terörist hareketler, Sözleşmede bir liste halinde sayılmıştır (m. 1, 2).

*Bu bakımdan, **terör olarak nitelendirilen fiiller, esasında suç oluşturan fiillerdir. Ancak, bu suçlar, belirli amaçlar doğrultusunda ve bir örgütün faaliyeti çerçevesinde sistematik bir şekilde işlendiği için, daha ağır sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.***

Terör eylemlerinin siyasi bir amaç güdülerek gerçekleştirilmesine rağmen, faillerinin cezasız kalmalarını önlemek için ve terörle mücadelede milletlerarası dayanışmanın gereği olarak; bu suçların, siyasi suç nedeniyle iade yasağının dışında tutulması yönünde bir milletlerarası irade oluşmuştur.

Başta terörizmin önlenmesine ilişkin sözleşmeler olmak üzere, çeşitli milletlerarası sözleşmelerde, sözleşme kapsamına giren suçlarla ilgili olarak “**aut dedere, aut punire**” (“cezalandır veya iade et”), “**aut dedere, aut judicare**” (“yargıla veya iade et”) kuralına yer verilmektedir. Bu kuralla, bir devlet, belli bir terör eylemini siyasi suç kabul ederek faillerini iade etmese bile, bu eylem nedeniyle yargılamak veya cezalandırmakla yükümlü kılınmıştır.

Türkiye'nin taraf olduğu, çeşitli terör eylemlerinin önlenmesine ilişkin sözleşmelerde bu kurala yer verilmiştir.

Örneğin 27.01.1977 tarihli **Tedhişçiliğin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin**¹⁷⁸ 1. maddesinde iade konusunda belirli bazı suçların, siyasi suç, siyasi suça murtabit (bağlantılı) suç ya da siyasal nedenle işlenmiş bir suç olarak nitelendirilemeyeceği belirtilmiştir. Maddede bu şekilde nitelendirilemeyecek suçlar sayma yöntemiyle belirtilmiştir:

a) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında La Haye Sözleşmesi ve Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi'nde belirtilen suçlar (m. 1/a, b). Böylece, ilgili sözleşmelerde yer alan suçların siyasi suç, siyasi suça murtabit (bağlantılı) yahut siyasi amaçla işlenmiş suç sayılamayacağı belirtilerek bu sözleşmelere yorum getirilmiştir¹⁷⁹.

b) Diploması Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair New

¹⁷⁸ Türkiye, Sözleşmeyi 27.10.1980 tarih ve 2327 sayılı Kanuna istinaden onaylamıştır. Sözleşme metni, 26 Mart 1981 tarihli ve 17291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁷⁹ BAYRAKTAR, Siyasal Suç, sh. 169.

York Sözleşmesi'nde yer alan suçların bir kısmı Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin kapsamına alınmıştır.¹⁸⁰

c) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma fiilleri (m. 1/d).

d) Bomba, el bombası, roket, otomatik ateşli silahlar, mektup ya da koli bombalar kullanılması fiilleri (m. 1/e). Bu fıkra hükmüne göre söz konusu eylemlerin bir yaralama ve ölüme neden olmaları gerekmez, kişiler için böyle bir tehlike yaratmaları yeterlidir.¹⁸¹

e) Söz konusu suçlara teşebbüs ve iştirak fiilleri (m. 1/f).

Bu nedenle, Tedhişçiliğin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi, taraf devletler arasındaki iadeye ilişkin anlaşmaların ilgili hükümlerini tamamlamakta ve hatta değiştirmektedir. Nitekim, Sözleşmenin 3. maddesinde, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi de dahil, taraf devletler arasında yürürlükte olan iade anlaşmalarında yer alan ve bu Sözleşme hükümleriyle bağdaşmayan hükümlerin değiştirilmiş olduğu belirtilmiştir. Ancak Sözleşme iade zorunluluğunu getirmemektedir, iade koşullarının belirlenmesinde yine taraflar arasındaki iade anlaşmalarındaki hükümlere bağlı kalınacaktır.

Sözleşmenin 2. maddesine göre hayat, vücut bütünlüğü ya da kişi özgürlüğü aleyhine işlenmiş olup 1. maddenin kapsamı dışında kalan diğer ciddi suçları taraf devletler, aralarındaki ilişkilerde iade bakımından siyasal suç sayabileceklerdir. Yine aynı maddenin 2. fıkrasına göre kişiler için kolektif bir tehlike teşkil ettiği takdirde mülkiyet aleyhine işlenen suçlar ve 3. fıkraya göre bu tür suçlara teşebbüs ve iştirak fiilleri de siyasi suç sayılmayabileceklerdir. Böylece 2. maddede belirtilen suçların siyasi suç olarak nitelendirilebilmeleri konusunda taraf devletlere bir takdir hakkı tanınmıştır.

6 ve 7. maddelerde, 1. maddede yazılı suçlar nedeniyle iadesi istenen bir kimseye iade etmeyen taraf devlete, olayı, gerekli takibatın yapılması amacıyla kendi yetkili yargı organları önüne getirme yükümlülüğü getirilmiştir.¹⁸²

¹⁸⁰ DONAY, Süheyl: *Tedhişçiliğin Cezalandırılması Hakkında Avrupa Sözleşmesi*, İstanbul ÜHFM, cilt XLIII, sayı 1-4, sh. 422, 423.

¹⁸¹ DONAY, (Tedhişçiliğin...), sh. 423.

¹⁸² Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerden örnek olarak şunlar zikredilebilir:

1) 14 Eylül 1963 tarihli **Uçaklara Karşı İşlenen Suçlara veya Diğer Fillere İlişkin Tokyo Sözleşmesi**, m. 16. Türkiye Sözleşmeyi 17.04.1975 tarih ve 1889 sayılı Kanuna dayanarak onaylamıştır. Sözleşme metni, 8 Aralık 1975 tarihli ve 15436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2) 16 Aralık 1970 tarihli **Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi hakkındaki La Haye Sözleşmesi**, m. 8. Türkiye Sözleşmeyi 30.11.1972 tarih ve 1634 sayılı Kanuna istinaden onaylamıştır. Sözleşme metni, 31 Mart 1973 tarihli ve 14493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

C. Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu

Devlet Başkanına karşı işlenen suçların iki özelliği bulunmaktadır. Üstlendiği kamu göreviyle bağlantılı olarak, bu görev dolayısıyla kişiye karşı suç işlenmekte ve işlenen suç, devlet başkanlığı görevini yürüten kişinin kişiliğine bağlı haklarına saldırı niteliğini taşımasıdır¹⁸³.

Devlet Başkanı aleyhine işlenen suçların siyasi suç olarak kabul edilmesine rağmen, iade hukuku bakımından siyasi suç sayılmamaları yolunda bir gelişme belirmiştir¹⁸⁴.

SİDAS'ın 3. maddesinin 3. bendinde “*İşbu sözleşmenin tatbikatı bakımından bir devlet reisinin veya ailesi efradından birinin hayatına kast siyasi suç sayılmayacaktır*” denilerek Belçika Kuralı'na yer verilmiştir.

Bu kural, içerikleri arasında farklılıklar bulunsada, Türkiye'nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarında yer almaktadır.

D. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suçun Siyasi Suç Olup Olmadığını Takdir Yetkisi

İade talebinin sebebini oluşturan suçun siyasi suç niteliğinde olup olmadığı, *ta-lepte bulunulan devlet* tarafından takdir edilir. Bu husus, SİDAS'ın 3. maddesinin birinci fıkrasında ve ayrıca Türkiye'nin taraf olduğu bir kısım iade anlaşmalarında¹⁸⁵ açıkça belirtilmiştir. İade anlaşmalarında yer alan bu konudaki hükümleri, aslında devletler hukuku sahasında var olan bir kuralın pozitif hukuka yansımaları olarak kabul etmekteyiz.

3) 23 Eylül 1971 tarihli **Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi**, m. 7, 8. Türkiye Sözleşmeyi 17.04.1975 tarih ve 1888 sayılı Kanuna istinaden onaylamıştır. Sözleşme metni, 29 Kasım 1975 tarihli ve 15427 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

4) 14 Aralık 1973 tarihli **Diploması Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair New York Sözleşmesi**, m. 7. Türkiye Sözleşmeyi 21.01.1981 tarih ve 2374 sayılı Kanuna istinaden onaylamıştır. Sözleşme metni, 1 Mayıs 1981 tarihli ve 17327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹⁸³ ÖZEK, Çetin: *Devlet Başkanına Karşı Suçlar*, İstanbul, 1970, sh. 111.

¹⁸⁴ Bu konuda ilk önce Fransız Ceza Kanununda 1853 yılında yapılan değişiklikle devlet başkanına karşı işlenen suçların siyasal suç sayılmayacakları kabul edilmiştir. Bilahare Fransa'da meydana gelmiş bir olayın Belçika'ya yansımaları üzerine 1856 yılında 1833 tarihli Belçika İade Kanunu'nun 6. maddesinde değişiklik yapılarak “Yabancı bir devlet reisinin şahsına veya ailesi efradına karşı yapılan suikast, bir cinayet veya zehirleme fiili ise ne siyasî suç ve ne de böyle bir suça murtabit suç telâkki edilmeyecektir” hükmüne yer verilmiştir. Ayn tarihte Belçika-Fransa arasındaki 1934 tarihli iade anlaşmasında yapılan değişiklikle buna paralel bir düzenleme getirilmiştir. Daha sonra iade hukukuna ilişkin gerek uluslararası anlaşmalarda ve gerekse iç hukuk düzenlemelerinde yer alan bu kural “**Belçika Kuralı**” olarak anılmıştır (ARMAOĞLU, sh. 1606; ÖZGEN, sh. 91; ÖZEK, sh. 124; BAYRAKTAR, sh. 140).

¹⁸⁵ İtalya(m.4/3), İsviçre(m.4/a), İran(m.3/bend 2), Yunanistan(m.2/8), Irak(m.6), Yugoslavya (1974, m.4/1), Macaristan(1982, m.19/1) ve Tunus(m.27).

Ayrıca iade talebinde bulunulan devlet yetkili organları, yaptıkları inceleme sonucunda suçun siyasi suç olmadığı sonucuna ulaşırsalar da, talebin siyasi düşüncelerle yapıldığı ya da talebin sebebini oluşturan suç nedeniyle iade edilmesi halinde kişinin durumunun siyasi nedenlerle bozulacağı, kanuni haklarından siyasi düşünceleri nedeniyle yoksun bırakılacağı kanaatine varırlarsa, yine bu talebi reddedebilecektir. Nitekim, SİDAS'ın 3. maddesinin ikinci fıkrasında bu husus açıkça düzenlenmiştir:

“Kendisinden iade talep edilen taraf, âdi bir suç için vâki iade talebinin bir şahsı ırk, din, milliyet veya siyasi kanaat cihetinden takip veya cezalandırmak gayesiyle yapıldığına veya bu şahsın vaziyetinin bu sebeplerden biri dolayısı ile ağırlaşabileceğine dair ciddi sebepler mevcut olduğuna kanaat hâsıl ettiği takdirde” geriverme talebini kabul etmeyecektir¹⁸⁶.

Aynı kural, 6706 sayılı Kanunda da yer almaktadır.

“Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde, ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle soruşturulacağına ya da kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez.” (m. 11, f. 1, bent b).

E. Siyasi Suç Nedeniyle İade Etmemenin Sonuçları

765 s. mülga TCK'nın kaynağını teşkil eden 1889 İtalyan Ceza Kanununun 7. maddesine göre, yabancı bir ülkede işlediği suç nedeniyle iadesi istenen yabancının, talebin sebebini oluşturan suçun siyasi suç olması nedeniyle iade edilmemesi halinde, talepte bulunulan devlette bu suç nedeniyle hakkında takibat yapılamayacaktır. Kaynak Kanunun bu hükmü 765 s. Kanuna alınmamıştı. Bu durum karşısında, Yargıtay 1.CD, 1949 yılında verdiği bir kararda¹⁸⁷, mülga 765 sayılı TCK'nın 6. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi durumunda siyasi suç nedeniyle iade edilmeyen bir yabancının Türk Mahkemelerinde yargılanabileceği sonucuna varmıştır. Yargıtay'ın söz konusu kararı, siyasi suç nedeniyle iade etmemenin dayandığı gerekçelerle bağdaşmadığı için eleştirilmiştir¹⁸⁸. Nitekim, 1.CD'nin bu kararı, esas mahkemesinin direnmesi üzerine, bu eleştiriler doğrultusunda CGK tarafından bozulmuştur¹⁸⁹.

Talebin sebebini oluşturan suçun siyasi suç olması nedeniyle iade edilmeme halinde, talepte bulunulan devlette yargılama yapılamayacağına ilişkin kurala, bazı milletlerarası anlaşmalarda istisna getirildiğini yukarıda terörizmin önlen-

¹⁸⁶ Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesinde de aynı kural tekrarlanmıştır.

¹⁸⁷ 13.04.1949 tarihli ve 1010/687 sayılı Karar.

¹⁸⁸ DÖNMEZER, (Yabancı...), 770; DÖNMEZER-ERMAN, III, 550; ÖZGEN, 106.

¹⁸⁹ CGK'nun 31.10.1949 tarihli ve 108/93 sayılı Kararı.

mesine ilişkin sözleşmeler bağlamında belirtmiştik. Bu istisna, “*aut dedere, aut punire*” (“ya iade et ya da cezalandır”) formülüyle ifade edilmiştir. Yeni TCK’nın 13. maddesinin gerekçesinde de bu hususa açıklık getirilmiştir:

“Türkiye’nin taraf olduğu çeşitli uluslararası sözleşmelerde aut dedere aut judicare/aut punire kuralına yer verilmek suretiyle ilgili sözleşme kapsamına giren suçlar dolayısıyla ister vatandaş olsun ister yabancı olsun faillerin suçun işlendiği ülkeye geri verilmesi öngörülmüştür. Ancak, bu sözleşmelerle, çeşitli hukuki mülahazalarla geriverme yoluna gidilmemesi hâlinde, taraf devletlere yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü yüklenmiştir.

Bu konuda, 1963 yılında imzalanan Uçaklara Karşı İşlenen Suçlara veya Diğer Fillere İlişkin Tokyo Sözleşmesi, 1970 yılında imzalanan Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi hakkındaki La Haye Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi, 14 Aralık 1973 tarihli Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair New York Sözleşmesi, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi, 21.12.1971 tarihinde Viyana’da imzalanan Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve ayrıca, Avrupa Konseyi’nce 27.01.1977 tarihinde hazırlanan Tedhişçiliğin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi örnek olarak gösterilebilir.”¹⁹⁰

F. Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu

Soykırım suçu, İkinci Dünya Savaşına öngelen yıllarda ve özellikle bu Savaş sırasında totaliter rejim taraftarlarının, insanları, siyasi, ırki ve dini sebeplerle öldürmeleri, sürgün etmeleri, insanlık dışı zulüm ve işkencelere tabi tutmalarına bir tepkinin sonucu ortaya çıkmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 09 Aralık 1948 tarihinde Paris’te **Genocide’nin Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme**¹⁹¹ kabul olunmuştur.

Sözleşmenin 1. maddesinde genosidin bir “devletler hukuku suçu” olduğu belirtildikten sonra; 2. maddesinde bir tanım verilmekte ve hangi fiillerin genosit kavramı içine girdiği belirtilmektedir. Buna göre:

“Jenosit, millî, etnik, ırki veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etmek amacıyla aşağıdaki fiillerden herhangi birinin irtikâp olunması demektir.

¹⁹⁰ Bu hususla ilgili olarak ayrıca bkz. ÖZGENÇ, İzzet: “*Non bis in idem*” Kuralının Milletlerarası Değeri ve TCK’nın 10/A Maddesi Hükmüne İlişkin Değerlendirme, in: Yargıtay Dergisi, cilt 28, Temmuz 2002, sayı 3, sh. 323 vd.

¹⁹¹ Türkiye Sözleşmeyi 23.03.1950 tarihli ve 5630 sayılı Kanuna istinaden onaylamıştır. Sözleşme metni, 26 Mart 1950 tarihli ve 7469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

- a) Grup azalarının katli,
- b) Grup azalarının bedeni veya aklî melekelerinin ciddî surette haleldar edilmesi,
- c) Grubun maddi varlığının kısmen veya tamamen imhasına müncer olacak hayat şartlarına kasten tabi tutulması,
- d) Grup içinde doğumları sekteye uğratacak tedbirler alınması,
- e) Bir grup çocuklarının diğer bir gruba zorla nakledilmesi.”

Yine, Sözleşmenin 3. maddesinde cezalandırılması gereken fiiller şöyle sıralanmıştır:

- a) Jenosit,
- b) Jenosit’i irtikâp için anlaşma,
- c) Jenosit’i irtikâp için doğurdan doğruya ve alenî surette tahrik,
- d) Jenosit’e teşebbüs,
- e) Jenosit suçunda ortaklık.

Sözleşmenin 7. maddesine göre, 3. maddede yer alan fiiller, iade hukuku bakımından siyasi suç olarak kabul edilmeyecektir.

Yine Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan SİDAS’a 15.10.1975 tarihli (1.) Ek Protokolde, savaş suçları ile insanlığa karşı işlenen suçların iade hukuku bakımından siyasi suç sayılmayacağı belirtilmiştir (m. 1).

6706 sayılı Kanuna göre de “soykırım ve insanlığa karşı suçlar, siyasi suç olarak kabul edilmez” (m. 11, f. 2).

G. Basın Suçları Nedeniyle İade Sorunu

Bütün basın suçlarının siyasi suç niteliği taşımadığı muhakkaktır. Basın ve yayın yoluyla işlenen suç işlemeye teşvik, hakaret ve müstehcenlik gibi suçların siyasi suç sayılmamasına rağmen; siyasi suçlara tahrik ve teşvik, devlet başkanına ve diğer kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret gibi suçlar, siyasi suç olarak kabul edilmelidir¹⁹². Bir siyasi suçun işlenmesinde basın ve yayın organları ancak araç olarak kullanılmaktadır¹⁹³. Basın ve yayın organlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen siyasi suçlar nedeniyle geriverme yoluna gidilmeyecektir¹⁹⁴. SİDAS’da basın suçları hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Türkiye’nin taraf olduğu eski tarihli ikili iade anlaşmalarında içerikleri farklı olmakla birlikte, bu hususta hükümlere yer verilmiştir¹⁹⁵.

¹⁹² BAYRAKTAR, 89.

¹⁹³ DÖNMEZER-ERMAN, III, 551; ÖZGEN, 114.

¹⁹⁴ DÖNMEZER-ERMAN, III, 551.

¹⁹⁵ Bulgaristan (1930, m.4/c), İsviçre (m. 4/b), Irak (m. 4/c), İtalya (m. 4/1), Almanya (m. 5/2), Çekoslovakya (m. 4/3), Macaristan (1934, m. 4/3), Yugoslavya (1936, m. 3/4) ve Yunanistan (m. 2/2).

H. Askeri Suçlar Nedeniyle İade Sorunu

Askeri suçların genel ve kapsamlı bir tanımını *Erman* vermektedir: “Sadece asker kişiler tarafından işlenmesi mümkün olup ta, TCK’nda kısmen veya tamamen öngörülme- yen ve askeri bir hizmet veya görevin ihlâlini ifade eden suçlarla, bu nitelikte olmamakla beraber askeri bir menfaati koruma maksadını güden ve As. CK tara- findan öngörülen veya yapılan atıf dolayısı ile bu kanunun uygulama alanına giren suçlar askeri suçlardır”¹⁹⁶. Bu tanımda da belirtildiği gibi askeri suçlar iki kategori- ye ayrılmaktadır. Buna göre, “bir asker kişi tarafından askeri bir hizmet veya göre- vin ihlâli sureti ile işlenip de, bu sıfatı haiz olmayan kimseler tarafından işlenmesi kabil olmayan ve genel ceza kanununda ne kısmen ve ne de tamamen öngörülme- yen askeri suçlar”^{a197} **sırf askeri suçlar**; “asker olmayan kimseler tarafından da işlen- mesi mümkün olup, askeri bir menfaati korumak gayesini güden, bütün veya bir kısım unsurları ile genel ceza kanunu’nda öngörülen ve askeri ceza kanunları tara- findan ayrıca belirtilen veya yapılan atıf dolayısı ile bu kanunların uygulama alanı içine alınan suçlar”^{a198} **askeri suç benzerleri** denilmektedir.

SİDAS’a göre, “cezaî hukuka göre suç teşkil etmeyen askeri suçlar dolayısıyla iade, işbu Sözleşmenin tatbik sahası dışındadır.”¹⁹⁹ (m. 4)²⁰⁰. Buna karşılık, askeri suç ben- zeri olarak nitelendirilen askeri suçlar, Sözleşmenin uygulama alanında tutulmuştur.

Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının büyük bir çoğunluğunda, sırf askeri suçlar nedeniyle iade isteminin kabul edilmeyeceği kuralı yer almıştır²⁰¹.

6706 sayılı Kanuna göre, Türkiye, bir kişiyi “sırf askeri suç niteliğinde” bir suç se- bebiyle iade edemez (m. 11, f. 1, bent c, alt bent 2). Dikkat edilmelidir ki, bu hü- kümdede, SİDAS’ta olduğu gibi, sırf askeri suçlar, iade kapsamı dışında tutulmuştur.

İ. Mali Suçlar Nedeniyle İade Sorunu

Devletlerin kendi aralarında yaptıkları bazı iade anlaşmalarında mali suçlar ne- deniyle iade yoluna gidilemeyeceğine ilişkin hükümler bulunmaktaysa da, bu konuda bir milletlerarası teamülün olduğu söylenemez. 6706 sayılı Kanunda

¹⁹⁶ ERMAN, Sahir: *Askeri Ceza Kanunu*, 7. bası, İstanbul, 1983, sh.151.

¹⁹⁷ ERMAN, sh. 151.

¹⁹⁸ ERMAN, sh. 151.

¹⁹⁹ Sözleşmenin Türkçe metninde “Cezaî hukuka göre suç teşkil etmeyen askeri suçlar” ibaresi yer almışsa da bu bir tercüme hatasıdır. Muteber İngilizce metne uygun ifade tarzı ise “genel ceza hukukuna göre suç teşkil etmeyen askeri suçlar” şeklinde olmalıdır.

²⁰⁰ Nitekim Nato Kuvvetler Sözleşmesi’nde sırf askeri kanunların ihlâl edilmesi nedeniyle kabul eden devlet ile gönderen devlet arasında asker ve sivil kişilerin teslimine ilişkin hükümler bu- lunmaktadır. (Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi, III/4 ve 5).

²⁰¹ Buna karşılık Belçika (m. 5/1), Irak (m. 4/b), Romanya (m. 19/a) ve Ürdün (m. 3/a) ile yapı- lan iade anlaşmalarında “askeri suç ve ona murtabit filler” deyimini kullanılarak askeri suç benzerleri dahi iade kapsamı dışında bırakılmıştır.

da, mali suçların geriverme kapsamı dışında tutulduğuna dair bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle Türk İade Hukukunda anlaşmalarda aksine hüküm bulunmadığı takdirde, mali suçlar nedeniyle iade yoluna gidilebilecektir.

SİDAS’a göre, “*Vergi, resim, kambiyo ve gümrük mevzularında işbu Sözleşmedeki şartlara tevfikan suçluların iadesi, ancak her suç veya suç kategorisi için bu hususun Âkid Taraflar arasında kararlaştırılmış olması halinde mümkündür.*” (m. 5) Bu düzenlemede, “*vergı, resim, kambiyo ve gümrük mevzuları*”ndan söz edilmekle mali suçlardan ne anlaşılması gerektiği bir ölçüde açıklandıktan sonra; mali suçlar nedeniyle iade yoluna gidilemeyeceği kural olarak kabul edilmiş ve ancak bunun aksinin taraflarca kararlaştırılabileceği belirtilmiştir.

Ancak Sözleşmeye 1978 yılında eklenen 2. Ek Protokole göre, söz konusu 5. madde şu şekle sokulmuştur (m. 2):

“1- Vergi, resim, gümrük ve kambiyo ile ilgili suçlar hakkında iade, (Avrupa) sözleşme(sı) hükümlerine uygun olarak, kendisinden iade talep edilen devletin kanununa göre aynı konuda bir suça tekabül ettiği taktirde akit taraflar arasında bahis konusu olacaktır.

2- İade, talep edilen tarafın hukukunun aynı çeşit vergi veya resmî düzenlemesi ya da iade talep eden taraf hukukundaki gibi bir vergi, resim, gümrük veya kambiyo düzenlemesi mevcut olmaması nedeniyle reddedilmeyebilir.”

Türkiye’nin taraf olduğu iade anlaşmalarından bir kısmında, içeriklerinde farklılıklar olmakla birlikte, mali suçlar nedeniyle iade yoluna gidilemeyeceği yönünde hükümlere yer verilmiştir²⁰².

J. Uyuşturucu Madde Suçları ve İade

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılmasının insanın fizik ve aklî sağlığına verdiği büyük zararlar ve bu maddelerin gittikçe yaygınlaşması nedeniyle devletler, kanunlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal edilmesini, ithal veya ihraç edilmesini, satılmasını, satın alınmasını, nakledilmesini, bulundurulmasını ve hatta kullanılmasını suç olarak tanımlamışlardır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin oluşturduğu kazanç cazibesi, dünyanın hemen her yerinde bu maddelere ilişkin uluslararası düzeyde organize bir suçluluk durumunun oluşmasına yol açmıştır²⁰³. Bu nedenle, 20. yüzyılın başlarından bu yana uyuşturucu maddelerle mücadele-

²⁰² Örneğin Yugoslavya ile 1974 yılında yapılan iade anlaşmasında (m. 6/1) malî suç “*gümrük, vergi, harç ve kambiyo alanındaki suçlar*” olarak belirlenmiştir. Aynı belirlemeyi Macaristan ile 1982 yılında yapılan iade anlaşması da benimsemiştir (m. 21/1). Ancak, bu iki iade anlaşmasında kural olarak malî suçlar iade kapsamı dışında bırakılmışsa da, tarafların nota tesisi suretiyle malî suçlardan bir kısmı veya tamamı hakkında iadenin kabul edilmesi konusunda anlaşabilecekleri belirtilmiştir (Yugoslavya, m.6/2; Macaristan, m.21/2)..

²⁰³ ERMAN, Sahir: *Uyuşturucu Maddelere İlişkin Ceza Hükümleri*, in: Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü Kutlama Çalışmaları Kollokyumlar ve Tartışmalar, İstanbul, sh.261.

le konusunda milletlerarası alanda işbirliği yapılmasına yönelik girişimler olmuştur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesinde bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda 30 Mart 1961 tarihinde, Türkiye'nin de taraf olduğu **“Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi”**²⁰⁴ hazırlanmıştır.

Sözleşmenin “Cezaî Hükümler” başlığını taşıyan 36. maddesinin birinci fıkrasında, kendi yasal düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, taraf devletler, *“uyuşturucu maddelerin işbu Sözleşme hükümlerine uygun olmayan bir şekilde yapılacak ekim ve istihsalinin, imalinin, istihracının, hazırlanmasının, elde bulundurulmasının, arzının, satışa, arzının, dağılımının, satın alınmasının, satışının, herhangi bir maksatla tesliminin, simsarlığının, gönderilmesinin, transit olarak şevkinin, naklinin, ithal ve ihracının veya sözü geçen Tarafın görüşüne nazaran, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olabilecek her türlü fiillerin kasten yapılmasının”* etkin ceza yaptırımlarını gerektiren suç olarak tanımlanması hususunda yükümlü kılınmıştır. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (ii) alt bendine göre, birinci fıkrada sayılan *“suçlardan herhangi birine kasten katılmak, suça ika maksadıyla birleşmek veya anlaşmak veya ikaina teşebbüs etmek ve işbu maddede bahis konusu suçlarla ilgili olarak kasten yapılan hazırlık fiilleri ile mali muameleler”* de suç sayılacaktır.

Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde *“1'inci fıkra ve 2'nci fıkranın (a) bendinin (ii) kısmında bahsedilen suçların, taraflar arasında imzalanmış veya imzalanacak olan suçluların geri verilmesi anlaşması hükümlerine göre gerivermeyi gerektiren birer vaka addolunması ve suçluların geri verilmesini bir anlaşmaya veya mütekabiliyete bağlamaya tarafların kendi aralarında geriverme hali olarak kabul olunması arzuya şayandır; şu kadar ki, geriverme, kendisine geriverme talebi yapılan tarafın mevzuatı uyarınca uygulanacak ve sözü geçen taraf yetkili makamları suçu yeter derecede ağır saymadıkları taktirde, suçlunun tevkifini veya geri verilmesini red hakkını haiz olacaklardır”* denilmektedir.

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (iv) alt bendinde, *“Yukarıda sözü edilen ağır suçlar, bunları ika edenler vatandaş veya yabancı olsun, suçun ülkesi üzerinde işlendiği tarafça, veya iade talebinin vaki olduğu tarafın mevzuatı gereğince suçlunun geri verilmesi şayanı kabul değilse ve söz konusu suçlu önceden takip ve muhakeme edilmemişse suçlunun ülkesi üzerinde bulunduğu tarafça takip olunacaktır”* denilerek, **“aut dedere aut punire”** kuralına yer verilmiştir.

Keza uyuşturucu ve uyarıcı madde suçluluğuyla mücadele amacıyla 21.2.1971 tarihinde Viyana'da **“Psikotrop Maddeler Sözleşmesi”**²⁰⁵ imzalanmıştır. Bu

²⁰⁴ Türkiye, Sözleşmeyi 27.12.1966 tarihli ve 812 sayılı Kanuna istinaden onaylamıştır. Sözleşme metni, 12 Mayıs 1967 tarihli ve 12596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

²⁰⁵ Türkiye, Sözleşmeyi 27.10.1980 tarihli ve 2326 sayılı Kanuna istinaden onaylamıştır. Sözleşme metni, 7 Mart 1981 tarihli ve 17272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sözleşmenin, ceza hukukuna ve özellikle iadeye ilişkin hükümleri, Tek Sözleşme'nin hükümlerinin bir tekrarı mahiyetindedir.

VII. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Dolayısıyla Talepte Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisine Sahip Olması

Suç oluşturan bir fiil nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapmaya, öncelikle suçun işlendiği ülke devleti yetkilidir. Bu kural, egemenlik hakkının bir sonucudur²⁰⁶. Bu nedenledir ki, iade talebinde bulunulan devlet, talebin sebebini oluşturan suç dolayısıyla yargılama yetkisine sahipse ve buna dayanarak soruşturma ve kovuşturma yapıyorsa, kişiyi iade etmeyecektir.

A. Suçun, Talepte Bulunulan Devletin Ülkesinde İşlenmiş Olması

Ceza Kanunlarının ülkeselliği kuralı gereğince talepte bulunulan devlet kendi ülkesinde işlenen bir suç nedeniyle iadeyi kabul etmez.

Nitekim, 6706 sayılı Kanuna göre, iadenin sebebini oluşturan suçun talepte bulunulan devlete nazaran “*yabancı ülkede işlenen bir suç*” olması gerekir (m. 10, f. 1).

Suçun icra hareketlerinin farklı devletlerin ülkelerinde işlenmesi ya da fiilin bir devlet ülkesinde icra edilmesi ve fakat neticesinin başka bir devlet ülkesinde meydana gelmesi durumunda, bu devletlerden her biri, suçun kendi ülkesinde işlendiğinden bahisle iade talebini reddedebilecektir.

SİDAS da aynı sonucu kabul etmiştir:

“Kendisinden iade talep edilen taraf, mevzuatına göre kısmen veya tamamen kendi ülkesinde veya ülkesi addolunan bir mahalde işlenmiş sayılan bir suçtan dolayı talep edilen şahsı iade etmekten imtina edebilir” (m. 7, f. 1).

Ancak Sözleşme, bu durumda talepte bulunulan devlete, “*imtina edebilir*” demekle takdir hakkı tanımıştır. Yani iade talebinde bulunulan devlet isterse bu durumlarda bile, kişiyi iade edebilecektir.

Türkiye'nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının tümünde, talepte bulunulan devletin, kendi ülkesinde işlenen suçlardan dolayı iade talebini reddedeceği kabul edilmiştir.

B. Suçun Kendi Ülkesi Dışında İşlenmesine Rağmen, İade Talebinde Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisinin Olması

Bazı durumlarda, suç teşkil eden fiil iade talebinde bulunulan devletin ülkesinde işlenmemiş olmasına rağmen, bu devlet suç nedeniyle yargılama yetkisine sahip olabilir.

Nitekim, 6706 sayılı Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk ka-

²⁰⁶ EREM, 228; ÖZGEN, 115.

nunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına olarak işlenmiş bir suç sebebiyle Türkiye’den başka bir devlete iade yoluna gidilemez (m. 11, f. 1, bent c, alt bent 3).

Bu düzenlemeye göre; yurt dışında işlenmiş olması dolayısıyla suçun işlendiği ülke devleti tarafından talepte bulunulsa bile,

- a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı,
- b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin zararına olarak²⁰⁷,
- c) Bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına olarak²⁰⁸,

işlenmiş suçlar, iade nedeni olamaz.

İade talep edilen devletin, kendi yargılama yetkisine dayanarak, kendi ülkesinde işlenmeyen bir suç nedeniyle ilgili kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatmış olduğu hallerde, iade talebini kabul etmeyeceği açıktır. Nitekim SİDAS’ın 8. maddesinde bu durumla ilgili hükme yer verilmiştir:

“Kendisinden iade istenilen taraf, iade talebine sebep olan bir veya birkaç fiilden dolayı kendisi hakkında takibat yapılmakta olduğu şahsın iadesini reddedebilir.”

İade talebine neden olan suç, talepte bulunan ve bulunulan devlet ülkeleri dışında işlenmiş bir suç olabilir. Bu ihtimalde, suçun işlendiği ülke devletinden başka bir devlet tarafından iade talebinde bulunulmaktadır. SİDAS’ın 7. maddesinin ikinci fıkrasında, bu hususla ilgili olarak şu hükme yer verilmiştir:

“İade talebine sebep olan suç iade talep eden tarafın ülkesi haricinde işlenmiş ise, ancak kendisinden iade talep edilen taraf mevzuatının, ülkesi dışında işlenen aynı çeşit bir suçun takibine müsaade etmemesi veya talep mevzuatını teşkil eden suç için iadeye cevaz vermemesi halinde iade ret olunabilir.”

Buna göre, talep edilen devletin Türkiye olması halinde, Türkiye’nin egemenlik alanı ve talepte bulunan devletin ülkesi dışında işlenmiş bir suçtan dolayı talep

²⁰⁷ Yurt dışında işlenmiş olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin elçilik ve konsolosluk binalarının, bu binalarda bulunan malvarlıklarının, KİT niteliğini haiz olan meselâ Ziraat Bankası A.Ş.’nin, Türk Hava Yolları A.O.’nun yurt dışındaki şube veya bürolarının zarar görmesini sonuçlayan suçlardan dolayı Türkiye’den iade talebinde bulunulması halinde, bu talep kabul edilmeyecektir.

²⁰⁸ Yurt dışında işlenmiş olup da mağdur Türk vatandaşı olan ya da zarar göreni Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisi olan suçlardan dolayı iade yoluna gidilemeyecektir. Çünkü, bu suçlardan dolayı 12. madde hükümleri gereğince Türk kanunlarına göre Türkiye’de yargılama yapılır. Bu nedenle Öztürk, 18. maddedeki söz konusu hükmün “gerek-siz” olduğunu ileri sürmektedir. ÖZTÜRK, Bahri: *Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Barosu Tarafından Düzenlenen TCK Tasarısı Çalışma Grubu Toplantı Notları*, in: *Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar*, Ankara, Eylül 2004, Türkiye Barolar Birliği yayını, sh. 320; ÖZTÜRK/ERDEM, 9. bası, sh. 84; ayrıca bkz. ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi I, 3. bası, sh. 264 vd.

eden devlete iade kararı verebilmek için, Türk kanunlarına göre yurt dışında işlenen bu suçtan dolayı Türkiye’de takibat yapılabilmesi gerekir.

Ancak, 6706 sayılı Kanunda bu hususta SİDAS’ın tam tersi bir hükme yer verilmiştir: Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç sebebiyle kişi bir başka devlete iade edilemez (m. 11, f. 1, bent c, alt bent 4). Bu düzenlemeye göre, talepte bulunan devletin ülkesi ile talepte bulunulan devlet olarak Türkiye’nin egemenlik alanı dışında işlenmiş bir suç nedeniyle, Türk kanunlarına göre Türkiye’nin yargılama yetkisi varsa, iade talebi kabul edilmeyecektir.

VIII. “Non Bis In Idem” Kuralı ve İade Sorunu. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Nedeniyle Kişi Hakkında Talepte Bulunulan Devlet Yargı Organlarınca Karar Verilmiş Olması

“*Non bis in idem*” kuralı, somut bir vakıayla ilgili olarak belli bir kişi hakkında bir soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ise, aynı şahıs hakkında aynı fiilden dolayı ayrıca soruşturma ve kovuşturma başlatılamayacağını ifade etmektedir. Keza, bu kural gereğince, somut bir vakıayla ilgili olarak belli bir kişi hakkında verilmiş bir hüküm mevcut iken; aynı şahıs hakkında aynı fiilden dolayı ayrıca soruşturma ve kovuşturma yapılamaz (5271 s. CMK, m. 223, f. 7)²⁰⁹.

“*Non bis in idem*” kuralı ceza yargısının değerlilik otoritesinin bir çeşidi olarak milletlerarası ceza uygulamalarında da söz konusu olmaktadır²¹⁰. Ceza yargısının milletlerarası değerinin sonucu olan²¹¹ “*non bis in idem*” kuralı gereğince, bir ceza uyuşmazlığı bir ülkede bir ceza yargısı ile sona ermiş ise, başka bir devlette aynı suçtan dolayı ve aynı kişi hakkında tekrar soruşturma ve kovuşturma yapılmamalıdır²¹². Dolayısıyla, bir ceza yargısı ile sona ermiş bir uyuşmazlığın konusunu teşkil eden suç nedeniyle iade talebiyle karşılaşan devlet, bu talebi reddedecektir.

Genel olarak “*non bis in idem*” kuralına, soruşturma evresinde C. savcısı tarafından verilen kovuşturmayaya yer olmadığı kararını da kapsayan geniş bir anlam verilmektedir²¹³.

“*Non bis in idem*” kuralı, SİDAS’ın 9. maddesinde de yer almıştır:

“Talep edilen şahıs hakkında kendisinden iade talep edilen tarafın salâhiyetli makamlarınca iade talebine sebep olan bir veya birkaç fiilden dolayı nihaî olarak karar verilmiş ise iadeye cevaz yoktur. Kendisinden

²⁰⁹ ÖZGENÇ, Yargıtay Dergisi, c. 28, Temmuz 2002, sh. 323 vd.

²¹⁰ KUNTER, Nurullah: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 7. bası, İstanbul, 1981, sh. 87.

²¹¹ KUNTER, sh. 229.

²¹² KUNTER, sh. 84.

²¹³ KUNTER, sh. 84, 88; İÇEL, Kayıhan: *Non Bis İn İdem Kuralının Milletlerarası Değeri*, in: İstanbul ÜHFM, cilt XXXVII, sayı 1-4, sh. 402.

iade talep edilen tarafın salâhiyeti makamlarınca aynı fiil veya fiiller hakkında takibat yapılmamasına veya yaptıkları takibata son verilmesine karar verilmiş ise iade talebi reddolunabilir.”

Bu hükümde, “*non bis in idem*” etkisi doğuran kararlar geniş tutulmuştur. Ancak, bu etkiyi doğuran kararlar arasında bir ayırım yapılmıştır. Şayet talepte bulunulan devlette talebin sebebini oluşturan suç nedeniyle kişi hakkında yapılan yargılama sonucunda bir hüküm verilmiş ve verilen hüküm kesinleşmiş ise, iade talebi **reddedilecektir**. Buna karşılık, Sözleşmedeki ifadeyle “*takibat yapılmamasına veya yapı(ılan) takibata son verilmesine*” karar verilmesi durumunda ise, “*iade talebi reddolunabilir.*” Başka bir ifadeyle, iade talebinin sebebini oluşturan fiil sebebiyle iade talep edilen devlette kovuşturmayaya yer olmadığı kararı verilmiş ise, iade talep edilen devlet bu talebi kabul edebileceği gibi ret de edebilir.

Keza işaret etmek gerekir ki, “*non bis in idem*” etkisi doğuran ve dolayısıyla, iade talebinin reddedilmesini gerektirecek kararın *iade talebinde bulunulan devlet yargı organlarınca* verilmesi gerekir.

Buna karşılık, Türkiye’nin taraf olduğu bazı iade anlaşmalarında²¹⁴ üçüncü bir devlet yargı organlarınca verilen kararların da iade uygulaması bakımından *non bis in idem* etkisini göstereceği kabul edilmiştir.

6706 sayılı Kanunda, bu bağlamda bir hükme yer verilmiştir: İadesi talep edilen kişi, talebin sebebini oluşturan fiil nedeniyle daha önce Türkiye’de yargılanmış ve hakkında **beraat** veya **mahkûmiyet** kararı verilmiş ise, iade edilemez (m. 11, f. 1, bent ç). Bu itibarla, söz konusu Kanun iade bakımından Türkiye’de verilmiş beraat veya mahkûmiyet kararına *non bis in idem* etkisi tanımıştır.

IX. Vatandaşın İade Edilmemesi Kuralı

Vatandaşın iade edilmemesi, milletlerarası uygulamada yerleşmiş bir kural halini almıştır. Bugün İngiltere ve Amerika’nın dışında bütün devletlerin iade hukuğu ile ilgili mevzuatında vatandaşın iade edilemeyeceği kuralı benimsenmiştir.

765 s. mülga TCK’nın 9. maddesinin birinci fıkrasında “*Bir cürümden dolayı bir Türk’ün ecnebi devletlere iadesi talebi Devletçe kabul olunamaz*” hükmüne yer verilmişti. Maddenin üçüncü fıkrasında da, aynı kurala dayalı bir düzenleme yer almaktaydı.

Vatandaşın iade edilmeyeceğine dair kural, anayasal düzeyde ilk defa 1982 Anayasasında yer almıştır: “*Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez*”(m. 38, f. 12). Ancak, bu hüküm, Anayasanın çeşitli maddelerinde değişiklik yapan **7.5.2004 tarihli ve 5170 sayılı Kanunla**, değiştirilmiştir (m. 5). Yapılan bu değişiklikle kural Türk hukuku bakımından yumuşatılmıştır:

²¹⁴ ABD (1980, m. 3/1-d ve 2-c), Tunus (m. 26/1-b), Suriye (1983, m. 3/1-d ve 2-d), Yugoslavya (1974, m. 3/c, d), Ürdün (m. 3/f, h), İran (m. 3/e).

“Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaşı, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.” (f. 12)

Aynı hüküm, 6706 sayılı Kanunda şu şekilde ifade edilmiştir:

“Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, iadesi talep edilen kişinin Türk vatandaşı olması” halinde *“iade talebi kabul edilmez”* (m. 11, f. 1 bent a).

SİDAS’da bu konuda kural koymaktan kaçınılmıştır: *“Her akit Taraf tebaasını iade etmemek hakkını haiz olacaktır”* (m. 6, f. 1, bent a). Böylece sözleşme, vatandaşın iadesi konusunu tarafların kendi aralarında yapacakları ikili iade anlaşmalarına ve iç hukuk düzenlemelerine bırakmıştır.

Türkiye'nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının tümünde vatandaşın iade edilmeyeceği kuralına yer verilmiştir²¹⁵.

İade talebinde bulunulan devlet, iadesi istenen kişinin kendi vatandaşı olup olmadığını kendi hukukuna göre belirler. Ayrıca bir başka devletin vatandaşı olup olmaması verilecek karar açısından önemli değildir.

Yeni TCK’ya göre, ceza hukuku uygulamasında *“vatandaş”* ibaresi, *“fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi”*yi ifade etmektedir (m. 6, f. 1, bent a). Buna karşılık, SİDAS, *iade kararının verildiği andaki vatandaşlığın* göz önünde bulundurulması gerektiğini kabul etmiştir (m. 6, f. 1, bent c). Ancak kural bu olmakla beraber vatandaşlık, iadeye karar verildikten sonra ve henüz teslim edilmeden önce kazanılmışsa, talepte bulunulan devlet, vatandaşı olması nedeniyle ilgili kişiyi iade etmemek hakkına sahip olacaktır. Bu durum karşısında şöyle bir yol izlemek gerekir. Somut olayda uygulama kabiliyeti bulan iade anlaşmalarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, TCK’nın 6. maddesi hükmü gereğince iade kararı verilirken, fiilin işlendiği sıradaki vatandaşlığı esas almak gerekecektir. TCK’nın düzenlemesi itibarıyla, fiilin işlendiği tarihten sonra Türk vatandaşlığının kazanılmış olması, iade edilmeye engel teşkil etmeyecektir. Keza, fiilin işlendiği tarihten sonra Türk vatandaşlığından çıkmış olsa bile iade yoluna gidilemez²¹⁶.

Türkiye'nin taraf olduğu ve halen yürürlükte bulunan ikili iade anlaşmalarında bu konuda bir hüküm bulunmamaktadır²¹⁷.

²¹⁵ Ancak ABD ile yapılan gerek 1923 tarihli ve gerekse 1980 tarihli iade anlaşmalarında vatandaşın iadesinin ancak karşılıklılık koşuluyla mümkün olabileceği kabul edilmiştir (1923, m.5; 1980, m. 4). Böylece vatandaşın iadesini kabul etmeyen Türk sistemi ile aksini kabul eden Amerikan sistemi arasında bir orta yol tutulmuştur.

²¹⁶ *Toroslu/Ersoy*, yeni TCK’da yer alan vatandaş tanımını, SİDAS’ın 6. maddesinin iade bağlamında vatandaşlığın aranacağı zamanla ilgili hükmüyle çeliştiği gerekçesiyle eleştirmektedir: *TOROSLU/ERSOY*, sh. 8 vd. Ayrıca bkz. *ULUTAŞ*, Suçluların Geri Verilmesi, sh. 60, 120 vd.

²¹⁷ Suriye ile 1940 yılında yapılan iade anlaşmasında (m. 3/2) fiilin işlendiği andaki vatandaşlığın iadeye karar verilirken göz önünde tutulacağı ve bu tarihten sonraki vatandaşlık değişikliklerinin iadeye engel olmayacağı kabul edilmişti.

6706 sayılı Kanuna göre, somut olayda iade şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda “*kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, ... karar verir.*” (m. 15, f. 1). Bu durum karşısında, ağır ceza mahkemesi, iadesi istenen kişinin Türk vatandaşı olup olmadığını tespit edecektir.

TCK’nın sistemine göre yurt dışında işlemiş bulunduğu suç nedeniyle iade edilmeyen vatandaş, Kanunun 11. veya 13. maddelerindeki şartların gerçekleşmesi halinde, Türkiye’de yargılanıp Türk Kanunlarına göre cezalandırılacaktır.

SİDAS, talepte bulunan devlete iade edilmeyen vatandaşın şartları varsa ülkede yargılanmasını sağlama yükümlülüğü getirmiştir. Buna karşılık, iade talebi reddedilen devlet, suçla ilgili bilgi, eşya ve dosyaları talebi reddeden devlete "mec-canen" gönderecektir. Bu durumda, iade talebi reddedilen devlet, iadesi istenen kişinin vatandaşı olduğu gerekçesiyle talebi reddeden devlet tarafından yapılan yargılama sonucundan haberdar edilecektir (m. 6, f. 2)²¹⁸.

X. Özel Haller Sebebiyle İade Sorunu

6706 sayılı Kanuna göre, “*İadesi talep edilen kişinin, talep tarihinde on sekiz yaşını doldurmamış olması, uzun zamandan beri Türkiye’de bulunuyor olması veya evli bulunması gibi kişisel hâlleri nedeniyle, iadenin kişinin kendisini veya ailesini, fiilin ağırlığı ile orantısız şekilde mağdur edecek olması durumunda iade talebi kabul edilmeyebilir.*” (m. 11, f. 4).

XI. İade Usulü

A. İade Talebinde Bulunulması ve Talepname (Talep Belgesi)

Belli bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık olan kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapmak ya da belli bir suçtan dolayı hükümlü bulunan bir kişinin cezasını infaz etmek yetkisine sahip bulunan devlet, bu kişinin, ülkesinde bulunduğu devletten bir “talepname” (“talep belgesi”) ile iadesini isteyecektir.

Belli bir suçtan dolayı mahkum olan kişinin iadesini istemek sorun teşkil etmemektedir. Buna karşılık, bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık konumunda olan kişinin iadesini istemek için sadece şüphe yeterli olmamaktadır. Olay, adli makamlara intikal ettirilmiş olmalı; işlenen suçun niteliği ve ihlal ettiği kanun maddeleri az çok belli olmalıdır.

İade talebinde bulunan devlet tarafından talepte bulunulan devlete gönderilen talepten, bu devletin iade konusunda vereceği kararda göz önünde bulundurulacağı birtakım bilgileri ihtiva etmesi gerekir. Bunlar, iadesi istenen kişinin kimliği ve eşkali, isnat olunan suçun türü ve niteliği, ihlal ettiği kanun hükümle-

²¹⁸ Bu konuda ayrıca örnek olarak bkz. ABD ile 1980 yılında yapılan anlaşmanın 4. maddesi ve Suriye ile 1983 yılında yapılan anlaşmanın 5. maddesi.

ri ve bu hükümlere göre suçun ne kadar cezayı gerektirdiği ve delillerin özetinden ibarettir.²¹⁹

SİDAS’a göre talepnamenin ihtiva etmesi gereken bilgiler şunlardır (m. 12, f. 2):

- a) İade talebinde bulunan devletin kanunlarına uygun bir biçimde verilmiş ve infaz kabiliyetini haiz bir mahkûmiyet hükmünün, tutuklama kararının veya yakalama emrinin ya da aynı güce sahip diğer bir kararın aslı veya tasdikli örneği.
- b) İade talebinin sebebini oluşturan fiilleri açıklayan bir belge; bu belgede fiillerin işlenme yer ve zamanı, hukuki nitelendirmesi ve uygulanacak kanuni hükümler açık bir şekilde gösterilecektir.
- c) Uygulanabilecek kanun metnlerinin bir örneği ve ayrıca iadesi istenen kişinin mümkün olduğu kadar açık eşkalini, uyrukluğunu ve kişiliğini belirlemeye yarayacak diğer bilgiler.

Talepnamede yer alan bilgi ve açıklamalar, iade talebinde bulunulan devlet tarafından bir karar verilmesi için yeterli görülmeyebilir. Bu durumda talepte bulunulan devlet, talepte bulunan devletten tamamlayıcı ek bilgi ve açıklamalar isteyebilir (SİDAS, m. 13). Bu bilgilerin ne kadar süre zarfında tamamlanması gerektiğini, tamamlayıcı bilgi isteyen devlet talebinde belirleyecektir.

Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının tümünde tamamlayıcı bilgi ve açıklama isteme hususunda hükümler yer almaktadır.

6706 sayılı Kanunda da bu bağlamda hükme yer verilmiştir. “*Merkezî Makam*” olarak ifade edilen Adalet Bakanlığı, “*iade taleplerini inceleyerek, lüzum görmesi hâlinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir ve gerekli şartları taşımayan talepleri reddeder.*” (m. 13, f. 1).

Talepnamenin hangi dille düzenleneceği konusunda da anlaşmalarda hüküm bulunmaktadır. SİDAS’ın 23. maddesine göre, talepname ve ona eklenecek diğer belgeler, talepte bulunan veya talepte bulunulan devletin diline göre hazırlanacaktır. Ancak, iade talep edilen devlet, bu belgelerle ilgili olarak, “*Avrupa Konseyinin resmî dillerinden* (bunlar, İngilizce ve Fransızca’dır) *seçeceği birisine yapılmış bir tercüme talep edebilir.*”

Bu hükmün yerinde olmadığı düşüncesindeyiz. Söz konusu belgelerin talepte bulunan devlet lisanına göre düzenlenmesi ve talepte bulunulan devlet lisanına tercüme edilmiş onaylı suretlerinin de eklenmesinin daha uygun olacağı düşüncesindeyiz. Nitekim, Türkiye’nin taraf olduğu iade anlaşmalarının çoğunda talepname ve eklerinin talepte bulunan devletin lisanına göre düzenlenmiş aslına istemde bulunulan devlet lisanına tercümelerinin onaylı suretlerinin de eklenmesi gerektiği kabul edilmiştir.

²¹⁹ TANER, sh. 244.

İade konusunda devletler arasındaki ilişki, kural olarak diplomatik yolla kurulmaktadır. Ancak bu yolun ağır işlemesi ve çok şekilci olması dolayısıyla, suçlular kolaylıkla ve çabuk bir şekilde yer değiştirerek izlerini kaybettirebilmektedirler.

SİDAS’da kural olarak diplomasi yolu kabul edilmiştir. Fakat, taraflar kendi aralarında yapacakları anlaşmalarla, iade talebinin iletilmesi konusunda başka bir yol kabul edebilirler (m. 12, f. 1).

Ancak Sözleşmeye 2. Ek Protokolün 5. maddesi ile, Sözleşmenin 12. maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, *iade talebinin doğrudan doğruya adalet bakanlıkları arasında yazışmak suretiyle yapılacağı kuralı* kabul edilmiştir. Ancak, bu düzenlemeye, diplomatik yol bertaraf edilmiş değildir.

Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının tümünde iade konusunda tarafların diplomatik yolla ilişki kuracakları kabul edilmiştir.

B. Talepnamenin İncelenmesi

Talepnamenin incelenmesi tamamen bir iç hukuk işidir. Bu nedenle bu konuda sadece iç hukuk düzenlemelerinde hüküm bulmak mümkündür. İade anlaşmalarında bu konuda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İç hukuk düzenlemelerinde talepnamenin incelenmesi bakımından adli, idari ve karma sistem olmak üzere üç farklı sistem mevcuttur.

765 s. mülga TCK’da (m. 9, f. 3 vd.) olduğu gibi, 6706 sayılı Kanunda da (m. 13, f. 1; m. 15; m. 18) *karma sistem* benimsenmiştir. Bu sisteme göre, Türkiye’den iade talebinde bulunulduğunda, yapılması gereken işlemleri şöylece sıralayabiliriz: Talepname, önce Dışişleri Bakanlığına gelir; oradan da Adalet Bakanlığına gönderilir.

Adalet Bakanlığı “*iade taleplerini inceleyerek, lüzum görmesi hâlinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir*” (6706 s. Kanun, m. 13, f. 1). “*Gerekli şartları taşıyan talepler, (Bakanlık tarafından) yetkili ağır ceza mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.*” (6706 s. Kanun, m. 13, f. 2).

“*İade talebi hakkında karar vermeye, kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi yetkilidir. Kişinin bulunduğu yer belli değilse, Ankara ağır ceza mahkemesi yetkilidir.*” (6706 s. Kanun, m. 15, f. 1).

“Cumhuriyet başsavcılığı, iade talebine ilişkin karar vermek üzere ağır ceza mahkemesinden talepte bulunur.” (6706 s. Kanun, m. 15, f. 2).

Mahkemenin ne gibi bir usul izleyeceği konusunda 6706 sayılı Kanunda belirli hükümler bulunmaktadır:

“İade yargılaması

MADDE 18- (1) *Kişinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi hâlinde mahkeme, iade şartlarını bu Kanun ve Türkiye’nin taraf olduğu*

milletlerarası andlaşma hükümlerine göre inceleyerek iade talebinin kabul edilebilir olup olmadığına karar verir.

(2) Talep eden devlet tarafından gönderilen belgelerin yeterli görülmesi hâlinde mahkeme, uygun bir süre içinde ek bilgi ve belgelerin gönderilmesini isteyebilir.

(3) İade yargılamasında katılma talebinde bulunulamaz.

(4) Mahkemenin kararına karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yargıtay bu başvuruları üç ay içinde sonuçlandırır. Kararın kesinleşmesi hâlinde iade evrakı karar ile birlikte Merkezî Makama gönderilir.”

Özel hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulama alanı bulacağı kuralından hareketle, burada da CMK'daki genel muhakeme kurallarına göre işlem yapmak gerekir. Buna göre, iade konusunda mahkemenin yapacağı inceleme, genel hükümler çerçevesinde, nizalı yargı esasına göre, açık ve yüze karşı duruşma yapılarak yerine getirilecektir. Duruşmada C. savcısı, iadesi istenen kişi ve müdafii bulunabilir.

Ağır ceza mahkemesinin inceleme alanı dar tutulmuştur. Mahkeme, iade talebini 6707 sayılı “Kanun ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümlerine göre inceleyerek” kabul edilebilir olup olmadığına karar verir (6706 s. Kanun, m. 18, f. 1).

Mahkeme önce, iadesi istenen kişinin Türk vatandaşı olup olmadığını belirleyecektir. Bu belirlemenin **29.5.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu** hükümleri çerçevesinde yapılacağına kuşku yoktur.

Keza mahkeme, iade talebinin sebebini oluşturan fiilin iade kapsamına giren bir suç olup olmadığını, Türkiye ile talep eden devlet arasında mevcut bulunan iade anlaşması ve 6706 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyecektir.

Buna göre mahkeme, iade talebinin sebebini oluşturan suçun siyasi suç (ve buna bağlı olarak düşünce suçu) ya da askeri suç olup olmadığını tespit edecektir. Bu belirleme yapılırken, Türkiye ile iade talebinde bulunan devlet arasında mevcut iade anlaşması ile her iki devletin müşterek tarafı olduğu ve iadeye ilişkin hükümler içeren diğer anlaşmaları göz önünde bulundurmak gerekir.

İade talebinin konusunu oluşturan suç nedeniyle başka bir iade engelinin bulunup bulunmadığını da mahkemenin incelemesi gerekir. Örneğin, mahkeme “*kişinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde, ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle soruşturulacağına ya da kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri*”nin var olup olmadığını tespit edecektir (6706 s. Kanun, m. 11, f. 1, bent b). Ancak, iade talebini inceleyen mahkeme, suçun işlenip işlenmediği gibi işin esasına yönelik bir inceleme yapmayacaktır.

Mahkeme yaptığı inceleme sonunda iadesi istenen kişinin Türk vatandaşı olduğu veya suçun siyasi suç (ve buna bağlı olarak düşünce suçu) ya da askeri suç olduğu ya da iade anlaşmalarına göre iade dışı bırakılan sair bir suç olduğu sonucuna varırsa **“iade talebinin kabul edilebilir olmadığına karar”** verecektir (6706 s. Kanun, m. 18, f. 1). Buna karşılık, kişinin Türk vatandaşı olmadığı ve suçun iade kapsamına girdiği sonucuna varılırsa **“iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar”** (6706 s. Kanun, m. 18, f. 1) verilir. Mahkemece bu konuda verilen karara karşı *“temyiz yoluna başvurulabilir.”* (6706 s. Kanun, m. 18, f. 4)²²⁰.

“Yargıtay bu başvuruları üç ay içinde sonuçlandırır.” (6706 s. Kanun, m. 18, f. 4). Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen karar, iade evrakı ile birlikte, Adalet Bakanlığına gönderilir.

Ağır ceza mahkemesince iade talebiyle ilgili olarak verilen karar, **hukuki nitelikte bir karardır.**

Mahkemece *“iade talebinin kabul edilebilir olmadığına karar”* verilmişse, artık yapılacak bir şey yoktur; kişi talep eden devlete iade edilmeyecektir. Buna karşılık mahkemece *“iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar”* verilmişse, *“bu kararın yerine getirilmesi, (yani kişinin iade edilmesi) Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayına bağlıdır.”* (6706 s. Kanun, m. 19, f. 1).

Adalet Bakanlığı, *“iade talebinin kabul veya ret edildiğini, talep eden devlete ve iadesi talep edilen kişiye bildirir.”* (6706 s. Kanun, m. 19, f. 2).

C. İade Sürecinde Koruma Tedbirleri

1) Geçici Tutuklama

İade talebinin yapılması bir çok işlemi ve formaliteyi gerekli kılmaktadır. Bu işlemlerin yapılıp gerekli evrakın hazırlanması ve ağır işleyen diploması yoluyla karşı tarafa gönderilmesi uzun bir zamanı gerekli kılmaktadır. Bu süre içinde iadesi istenen kişi, seri ulaşım araçlarıyla kaçmayı ve izini kaybettirmeyi rahatlıkla sağlayabilir. İşte bu sakıncalı durumu ortadan kaldırmak için, SİDAS’da ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer ikili iade anlaşmalarının tümünde, talepname diploması yoluyla henüz diğer devlete gönderilmeden önce, talepte bulunacak devletin savcılık ve hatta kolluk makamları tarafından diğer devlet yargı organlarına doğrudan doğruya başvurularak, ilgili kişinin yakalanıp tutuklanmasının istenebilmelerine imkan tanıyan hükümlere yer verilmiştir.

Geçici tutuklama, SİDAS’ın 16. maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeye göre ancak acele durumlarda geçici tutuklama istenebilecektir. Geçici tutuklama talebinde bulunulabilmesi için iadesi istenecek kişi

²²⁰ Ayrıca bkz. 4. CD’nin 26.12.1932 tarihli ve 11706/10255 sayılı Kararı.

hakkında bir mahkumiyet hükmünün, tutuklama kararının veya yakalama emrinin verilmiş olması ve bu durumun geçici tutuklama talebinde belirtilmiş olması gerekir (SİDAS, m. 16, f. 1).

Ayrıca, geçici tutuklama talepnamesinde, daha sonra yapılacak iade talebinin sebebini oluşturan fiil, bu fiilin işlendiği yer ve zaman, söz konusu kişinin eşkali mümkün olduğunca anlatılacaktır (SİDAS, m. 16, f. 2). Geçici tutuklama talepnamesi ile, talepte bulunulan devlette bir iade talebinin yapılacağına dair kanaatin oluşmasının sağlanması gerekir.

Geçici tutuklama talebi, diğer devlet yargı organlarına diplomasi yoluyla ya da doğrudan doğruya posta, telgraf veya İTERPOL (Milletlerarası Cınai Polis Teşkilatı) aracılığı ile iletilebilir (SİDAS, m. 16, f. 3).

SİDAS’da, geçici tutuklama talebi karşısında, talepte bulunulan devletin kendi kanunlarına göre yetkili organları tarafından geçici tutuklamaya karar verileceği kabul edilmiştir (m. 16, f. 1). Geçici tutuklama talebi hakkında Türkiye’de karar vermeye yetkili organ sulh ceza hakimliğidir.

Sulh ceza hakimi, geçici tutuklama kararı verme konusunda takdir yetkisini haizdir. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu iade anlaşmalarının çoğunda geçici tutuklama talebinde bulunulduğunda talepte bulunulan devletçe geçici tutuklamaya karar verilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Artık bu durumda söz konusu anlaşmaların tarafları arasındaki geçici tutuklama talepleri bağlamında sulh ceza hakiminin takdirinden söz edilmeyecektir.

SİDAS’da geçici tutuklama talebi üzerine talepte bulunulan devlet yargı organlarının verdiği kararlar ilgili olarak, talepte bulunan devlete bilgi verileceğine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarında ise, geçici tutuklama talebinde bulunulan devletin talepte bulunan devlete bilgi verme yükümlülüğü kabul edilmiştir. SİDAS açısından bu durumun bir eksiklik olduğunu düşünmekteyiz.

SİDAS’a göre, geçici tutuklama kararından sonra onsekiz gün içinde iade talebinde bulunulmazsa tutuklama sona erecektir. Ancak kabul edilebilir bir gerekçeye dayanılarak geçici tutuklama süresinin uzatılması istenebilir. Fakat her halde bu süre kırk günü aşmayacaktır. Bu hükümler çerçevesinde tutuklanan kişi serbest bırakıldıktan sonra iade talebinde bulunulursa, serbest bırakma tekrar tutuklamaya ve iade etmeye engel teşkil etmeyecektir (SİDAS, m. 16, f. 4, 5).

Dikkat edilmelidir ki, bu geçici tutuklamanın 5271 s. CMK’nın 100 vd. maddelerinde koruma tedbiri olarak düzenlenen tutuklama ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim, 6706 sayılı Kanunda geçici tutuklama ile ilgili olarak şu hükme yer verilmiştir:

“Geçici tutuklama

MADDE 14- (1) İade talebine konu olabilecek bir suçun işlendiğinin kabulü için kuvvetli şüphe bulunması hâlinde, iade talebinin Merkezî Makama

ulaşmasından önce, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümleri veya mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, ilgili devletin talebi ve Merkezî Makamın uygun bulması üzerine kişi geçici olarak tutuklanabilir.

(2) İade talebine konu olabilecek ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamına giren bir suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişi, ilgili devletin talebi aranmaksızın geçici olarak tutuklanabilir.

(3) İlgili devletin geçici tutuklama talebi, Merkezî Makam tarafından iade amacıyla yakalanması ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkî için İçişleri Bakanlığına gönderilir. Yakalanan kişi, geçici tutuklama hususunda karar verilmek üzere en geç yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır. Sulh ceza hâkimi geçici tutuklanması talep edilen kişiye, rızaya dayalı iade imkânı ile bunun hukukî sonuçları hakkında bilgi verdikten sonra talep hakkında karar verir.

(4) Geçici tutuklama süresi ilgili milletlerarası andlaşma hükümlerine göre belirlenir. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde kişi, en fazla kırk gün geçici tutuklu kalabilir.

(5) Geçici tutuklama yerine kişinin kaçmasına engel olacak şekilde Ceza Muhakemesi Kanununun 109'uncu maddesi uyarınca adli kontrol kararı verilebilir.

(6) İlgili devlet tarafından dördüncü fıkra belirtilen süre içinde iade evrakının gönderilmemesi hâlinde geçici tutuklama veya adli kontrol kararı kaldırılır. Bu durum, iade talebinin alınmasından sonra iade amacıyla koruma tedbirleri uygulanmasına engel teşkil etmez.”²²¹

2) Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri

İade anlaşmalarının bir kısmında tutuklamanın yanı sıra diğer birtakım koruma tedbirlerinin de alınabileceği kabul edilmiştir. Tutuklanması gereken kişinin ele geçirilebilmesi için örneğin telekomünikasyon yoluyla iletişiminin izlenmesi gerekiyorsa, bu gibi koruma tedbirleri talepte bulunulan devletin kanunlarına göre uygulanabilmelidir²²². Yine, yeni tarihli iade anlaşmalarına göre, talepte bulunulan devlet, iade talebi karşısında, iade talebinin sebebini oluşturan suç göz önünde bulundurulmak suretiyle kendi kanunlarına göre alınması gereken bütün koruma tedbirlerini alacaktır²²³.

²²¹ İadesi istenen kişinin tutukluluk durumu otuz günlük sürlerle incelenmeksizin, müteaddit tahliye talepleri hakkında bir karar verilmeden tutukluluğunun devam ettirilmesi, hak ihlali sebebi oluşturmaktadır: Anayasa Mahkemesi, 19.12.2023, BB. 2021/28076.

²²² Türkiye'nin İtalya (m. 9/2), Çekoslovakya (m. 8/2), Macaristan(1934, m. 8/2) ve İsviçre(m. 9/2) ile imzalamış olduğu iade anlaşmaları, bu konuda örnek olarak gösterilebilir.

²²³ Romanya (m. 21), Yugoslavya (1974, m. 14), Ürdün (m. 8), Bulgaristan (1977, m. 19), ABD (1980, m. 9), Macaristan (1982, m. 25), Tunus (m. 31), Suriye (1983, m. 10).

6706 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle, iade talebinin Türkiye'ye verilmesinden sonra, ağır ceza mahkemesi tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin olarak karar verme hususunda özel olarak yetkilendirilmiştir:

“İade amacıyla koruma tedbirlerinin uygulanması

MADDE 16- (1) *Ağır ceza mahkemesi iade sürecinin her aşamasında iadesi talep edilen kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca koruma tedbirlerine karar verebilir.*

(2) *İade sürecinde kişinin tutuklanması durumunda teslimi kadar geçen süre içindeki tutukluluk durumu, ağır ceza mahkemesince en geç otuzar günlük sürelerle incelenir.*

(3) *Ağır ceza mahkemesinin iade talebinin kabulüne ilişkin kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde 19'uncu maddeye göre iade kararı verilmemesi hâlinde kişi hakkındaki koruma tedbirleri kaldırılır.*

(4) *Toplam tutukluluk süresi, kişinin iade talebine konu suçtan dolayı alabileceği veya mahkûm olduğu cezanın infaz süresini geçemez.”*

D. Birden Fazla İade Talebi Karşısında Karar Verilmesi

Aynı kişinin değişik devletler tarafından aynı zamanda aynı fiil veya farklı fiiller nedeniyle iadesinin istenmesi durumunda kural, iade isteminde bulunulan devletin bu istemlerden bir tanesini tercih etmede tam bir serbestiye sahip olmasıdır.

SİDAS'ın 17. maddesinde, bir kişinin değişik devletlerce aynı fiilden veya değişik fiillerden dolayı aynı zamanda iadesi istenildiğinde talepte bulunulan devlete takdir serbestisi tanınmıştır.

Türkiye'nin taraf olduğu yeni tarihli iade anlaşmalarında SİDAS'daki kuralla paralel bir düzenleme getirilmiştir²²⁴.

Benzer içerikte bir hükme 6706 sayılı Kanunda da yer verilmiştir:

“Aynı kişi hakkında birden fazla devlet tarafından iade talebinde bulunulması hâlinde, suçların ağırlığı ve işlendiği yer, taleplerin geliş sırası, kişinin vatandaşlığı ve yeniden iade edilme ihtimali gibi şartlar dikkate alınarak, iade taleplerinden hangisinin öncelikli olarak işleme alınacağı Merkezî Makam tarafından belirlenir.” (m. 10, f. 3).

E. İade Talebinde Bulunulmasının Teklif Edilmesi

Bazı iade anlaşmalarında, başka bir ülkede işlediği suçtan dolayı o ülkede şüpheli, sanık veya mahkûm olan kişinin kendi topraklarında bulunduğundan haberdar olan devletin, durumu suçun işlendiği devlet makamlarına bildirerek iadesini istemelerini teklif edebileceği hususunda hüküm bulunmaktadır.

²²⁴ Yugoslavya (1974, m. 16), ABD (1980, m. 12), Macaristan (1982, m. 30), Tunus (m. 34) ve Suriye(1983, m. 14).

Yeni TCK'nın 12. maddesine göre, bir yabancınn yurt dışında yine bir yabancıya karşı işlemiş bulunduđu suçtan dolayı Türkiye'de yargılanabilmesi için aranan şartlardan birisini, “*geri verilme isteminin suçun işlendiğı ülkenin ... hükûmeti tarafından kabul edilmemiş olması*” oluşturmaktadır (f. 3, bent b). Bu düzenleme ile, Türkiye'nin suçun işlendiğı ülke devletine iade talebinde bulunmasını teklif edebileceğı kabul edilmiştir.

F. İadesine Karar Verilen Kişinin Talepte Bulunan Devlete Teslim Edilmesi

İade talebinde bulunulan devlet, bu talep dolayısı ile verdiği kararı istemde bulunan devlete bildirecektir. Talep üzerine verilen karar tamamen veya kısmen ret şeklinde ise, talepte bulunulan devlet kararında bu reddin gerekçesini gösterecektir. Buna karşılık, verilen karar talebin kabulü şeklinde ise, istemde bulunulan devlet iadesi kabul olunan kişinin teslim edileceğı yer, tarih ve iade edilmek üzere tutuklu kaldığı süre hakkında diğer devlete bilgi verecektir. İade talebi üzerine verilen kararın diğer tarafa bildirilmesi, kural olarak yine iade talebi için izlenen yol olan diplomasi yolu ile yapılacaktır.

Bu konuda gerek SİDAS'da (m. 18) ve gerekse Türkiye'nin yeni tarihli iade anlaşmalarında²²⁵ hükümler bulunmaktadır.

İadesine karar verilen kişi, belirlenen tarih ve yerde, talepte bulunulan devlet güvenlik kuvvetlerince, iade isteyen devlet yetkililerine teslim edilir.

İade isteyen devlet, iade kararında belirtilen zamanda iadesine karar verilen kişiyi teslim alması için gereken hazırlıkları yapmalıdır. İadesi istenen kişi belirtilen yerde ve zamanda teslim alınmadığı takdirde ortaya çıkan durumla ilgili olarak gerek SİDAS'da (m. 18) gerek diğer iade anlaşmalarında hükümler bulunmaktadır.

İki ülkenin sınırları bitişik olduğunda teslim işlemi kolaylıkla yapılır. Fakat iki devlet arasında başka devletler bulunmakta ise, iade edilen kişi bu devletlerden transit olarak geçirilmek zorundadır.

İki devlet arasında ortak sınır noktaları yoksa ve doğrudan doğruya deniz yolu ile ulaşım sağlanamıyorsa, iadesine karar verilen kişi bir üçüncü veya daha fazla devletin egemenliğinin bulunduğu topraklar üzerinden transit olarak geçirilmek zorundadır.

Gerek SİDAS'da (m. 21) gerek Türkiye'nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının çoğunda taraf devletler birbirlerine, taraflardan birinin bir üçüncü devletten iade talebinde bulunması durumunda iadesine karar verilen kişiyi kendi ülkesinden geçirmeyi taahhüt etmektedirler. Ancak bu transit iade isteminin kabul edilebilmesi için de genel iade koşullarının aranacağı anlaşmalarda açıkça belirtilmiştir.

²²⁵ Romanya (m. 24), Yugoslavya (1974, m. 15), Ürdün (m. 10), Bulgaristan (1977, m. 22), ABD (1980, m. 11), Macaristan (1982, m. 29), Tunus (m. 36), Suriye (1983, m. 12).

SİDAS'ın 21. maddesinin dördüncü fıkrası transit geçişin hava yolu ile yapılması durumunda çeşitli ihtimalleri düzenlemektedir: Buna göre, eğer hava yolu ile geçiş halinde transit devlet toprağına inilmeyecek ise, ilgili devletin durumdan sadece haberdar edilmesi ve iade edilen kişinin hükümlülük veya tutukluluk kararını içeren belgenin gönderilmesi yeterli olmaktadır. Ayrıca izin istemeye gerek yoktur²²⁶.

Benzer içerikte bir hükme 6706 sayılı Kanunda da yer verilmiştir:

“Teslim

MADDE 20- (1) İadesine karar verilen kişinin teslim işlemleri, ilgili bakanlıklarla iş birliği hâlinde yürütülür.

(2) İadesine karar verilen kişinin, talep eden devlet makamları ile kararlaştırılan tarihte haklı bir neden olmaksızın teslim alınmaması hâlinde, bu tarihten itibaren otuz gün sonra mahkemece kişi hakkında verilen koruma tedbirleri kaldırılır.

(3) İadesine karar verilen kişi hakkında, başka bir suç nedeniyle Türkiye’de ceza soruşturması veya kovuşturması ya da infazı gerekli bir hapis cezası bulunması veya kişinin seyahat edebilecek durumda olmaması hâlinde, Merkezî Makam tarafından teslimin ertelenmesine karar verilebilir. Bu karar, kişiye ve talep eden devlete bildirilir.

(4) İade talebine konu suç bakımından ispat aracı olarak yararlı görülen veya suçun işlenmesiyle elde edilen ve kişi yakalandığında üzerinde ele geçen ya da daha sonra ortaya çıkan eşya, talep eden devlete teslim edilebilir. İadesi talep edilen kişinin ölümü, kaçması veya benzer sebeplerle iade hakkında bir karar verilememesi hâlinde de eşyanın teslimi gerçekleştirilebilir.

(5) Türkiye’de yürütülmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bakımından zorunlu olduğu takdirde eşyanın teslimi ertelenebilir.

(6) İyiniyetli üçüncü kişilere ait eşyanın teslim talepleri yerine getirilmez.”

G. Teslimin Ertelenmesi

İadesi istenen kişi hakkında iadeye neden olan suçtan başka bir suç nedeniyle talepte bulunulan devlette soruşturma veya kovuşturma yapılmakta ya da kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı varsa, bu kişinin talepte bulunan devlete teslimi, soruşturma ve kovuşturmanın ya da hükmolunan cezanın infazının tamamlanmasına kadar ertelenebilir. Ancak teslimin ertelenmesi iade talebi ile ilgili olarak karar vermeye engel değildir.

²²⁶ Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarından ABD (1980) ile yapılan anlaşmanın 18. maddesinde ve Tunus ile yapılan anlaşmanın 41. maddesinde SİDAS’nin havayolu ile transit geçişe ilişkin düzenlemesi aynen kabul edilmiştir.

SİDAS'ın 19. maddesinin birinci fıkrasında ve Türkiye'nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarında bu hususta hükümlere yer verilmiştir.

H. Geçici İade

Teslimin ertelenmesi özellikle uzun süreli ceza mahkumiyetinin infazı nedeniyle kararlaştırılmışsa, bu durum, talepte bulunan devlet ülkesinde suç delillerinin tazeliğini yitirmesine veya kaybolmasına yada suçun zamanaşımına uğramasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda teslimin ertelenmesi yoluna gidilmeyip, kişi geçici ve koşullu olarak iade edilir. Şüpheli veya sanık konumundaki kişiyi teslim alan devlet yargılanmasını bitirir veya zamanaşımını kesen işlemleri yapar, sonra tekrar iade eden devlete teslim eder. Kişi önce iade etme kararı veren devlette mahkum olduğu cezasını çeker ve sonra iade edilen devletteki cezasını çekmek üzere bu devlete kesin olarak teslim edilir.

Gerek SİDAS'ın 19. maddesinin ikinci fıkrasında ve gerekse Türkiye'nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarında geçici iade ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.

İ. Eşya ve Değerlerin Teslimi

İade kararının sebebini oluşturan suçla ilgili olan ve talepte bulunulan devletin ülkesinde bulunan eşya ve değerlere el konularak, bunlar da ilgili kişi ile beraber veya daha sonra talepte bulunan devlete teslim edilecektir.

Gerek SİDAS'ın 20. maddesinde ve gerekse Türkiye'nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarında eşya ve değerlerin teslimi konusunda ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre, a) suçun işlenmesinde kullanılan veya delil teşkil edebilecek eşya, b) işlenen suçun sonucunda elde edilmiş olup iadesi istenen kişinin tutuklandığı anda elinde bulunan veya daha sonra ortaya çıkan eşya ve değerler, c) işlenen suçtan elde edilen eşya karşılığında sağlanan değerler. Bu eşya ve değerlere, talepte bulunulan devletin kanunlarına göre el konularak; talepte bulunan devlete teslim edileceklerdir. Bu el koyma ve teslim, SİDAS'a (m. 20/1) ve diğer iade anlaşmalarına²²⁷ göre, ancak talepte bulunan devletin isteği üzerine yapılabilir.

J. İade Harcamaları ve Bu Harcamaların Karşılanması

İade, iki veya daha fazla devlet arasında yazışmayı, iadesine karar verilen kişinin teslimini ve iadeye neden olan suçla ilgili eşya ve değerlerin teslimini gerektirir. Bu işlemler de doğal olarak birtakım harcamaları zorunlu kılmaktadır. Bu harcamaların hangi devlet tarafından karşılanacağı konusunda farklı sistemler mevcuttur²²⁸. Gerek SİDAS'da (m. 24) ve gerekse ikili iade an-

²²⁷ Belçika (m. 9), Romanya (m. 28), Yugoslavya (1974, m. 22), Ürdün (m. 14), Bulgaristan (1977, m. 26), ABD (1980, m. 15), Macaristan (1982, m. 34), Tunus (m. 35), Suriye (1983, m. 15).

²²⁸ Bu sistemler için bkz. ÖZGEN, 150.

laşmalarının tümünde kabul edilen sisteme göre, her devlet kendi ülkesinde yapılan harcamaları karşılayacaktır. Ancak transit geçiş için yapılan harcamaları iade talebinde bulunan devlet karşılayacaktır²²⁹.

XII. İadenin Sonuçları

A. İadede Özellik Kuralı

İadesine karar verilen kişinin tesliminden sonra, iade edilen devletin birtakım esaslara uygun hareket etmesi gerekir. **Gerivermede özellik (iadede hususilik) kuralı** gereğince; iade edilen devlet ancak talepten önce belirtilen fiillerden dolayı soruşturma ve kovuşturma yapabilecektir veya mahkum olduğu cezayı infaz edebilecektir.

Bu kural ile güdülen amaç, kişinin iade edildiği devlette haklarının korunmasıdır. Bu kural ile, birtakım hileli yollarla iadeye elverişli olmayan suçlar gizlenerek, göstermelik adı suçlar yüzünden iade talebinde bulunulması önlenmiş olur. Ayrıca, iade bir egemenlik tasarrufudur. Somut iade işlemi iki devlet arasında bir tür anlaşma sayılacağından iade edilen devletin bu anlaşmaya sadık davranması gerekir.

Talepten önce belirtilen suçtan başka herhangi bir fiil nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapılamaz veya hükmolunmuş ceza infaz edilemez. Ancak bu sınırlama, iade edilen kişinin *tesliminden önce* işlemiş olduğu suçlar için geçerlidir. Buna karşılık, teslimden sonra herhangi bir suç işlenmişse, özellik kuralı bu suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapılmasına engel değildir.

Özellik kuralı SİDAS'ın 14. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir:

“İade edilen şahıs iadede evvel ika ettiği ve iadeye esas olandan başka bir fiilden dolayı takip ve muhakeme edilemeyeceği gibi bir ceza veya emniyet tedbirinin infazı için tevkif edilemez ve keza her hangi bir surette hürriyeti kısıtlamaz”.

Kural, Türkiye'nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının tümünde düzenlenmiştir.

Özellik kuralı, 6706 sayılı Kanunda da düzenlenmiştir:

“İade hâlinde, kişi ancak iade kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya kişinin mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir.”
(m. 10, f. 4).

Bu düzenlemede, *Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Üçüncü Protokol* ile *Ek Dördüncü Protokol* hükümleri dikkate alınmıştır.

²²⁹ Yugoslavya (1974, m. 22/3) ve Macaristan (1982, m. 34/3) ile yapılan anlaşmalarda, iadeye neden olan suçla ilgili eşya ve değerlerin teslimi önemli harcamaları gerektiriyorsa, bunları iade talebinde bulunan devletin karşılayacağı kabul edilmiştir.

B. İadeye Neden Olan Fiilin Niteliğinde Değişiklik Meydana Gelmesi

İadeden sonra yapılan soruşturma ve kovuşturma sırasında, iadeye neden olan fiilin niteliğinde değişiklik meydana gelmesi, örneğin siyasi, askeri veya diğer iadeye elverişsiz suçlardan birini oluşturduğunun anlaşılması halinde, iade edilen devlet yargılamaya bırakıp kişiyi serbest bırakmalıdır.

Buna karşılık fiilin, niteliğinde bir değişiklik meydana gelmesine rağmen, yine de iadeye elverişli bir suç olma vasfını taşıması halinde iki ihtimal düşünülebilir.

Fiilin, bilahare daha hafif cezayı gerektiren bir suç oluşturduğunun, örneğin kasten öldürme olarak nitelendirilmişken, yargılama sırasında neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçunu oluşturduğunun anlaşılması halinde; kanaatimizce, iade edilen devletin yargılamaya devam edebilmesi için iade eden devletten muvafakat almasına gerek yoktur²³⁰.

Fiilin, bilahare daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturduğunun anlaşılması halinde; kanaatimizce, aynı şekilde hareket etmek gerekir²³¹.

Nitekim, SİDAS'da bu iki ihtimal arasında bir ayırım gözetilmeksizin düzenleme yapılmıştır:

“Suç addolunan fiilin evsafı takibat esnasında değişmişse, iade edilen şahıs hakkında ancak yeniden tavsif edilen suçun unsurları iadeyi icabettiriyorsa, takibat ve mahkeme yapılabilir.” (m. 14, f. 3)

C. Özellik Kuralının Etkisinin Ortadan Kalktığı Haller

1) İade Eden Devletin Talepnamede Belirtilmeyen Suçlar Dolayısıyla da Yargılamaya İzin Vermesi

İadede özellik kuralı gereğince talepnamede gösterilmemiş fiiller nedeniyle iade edilen devlet tekrar, iade eden devlete bir talepname göndererek, iade edilen kişinin söz konusu fiillerden dolayı da yargılanmasına muvafakat etmesini ister.

Nitekim SİDAS'a göre,

“İade edilen tarafın buna muvafakat etmesi. Muvafakati istihsal için bir talepte bulunulacak ve buna 12. maddede mezkûr belgeler ile iade edilen şahsın suça müteallik olarak yaptığı beyanın zaptı eklenecektir. Muvafakat, ancak şahsın talep edilmesine sebep olan suçun bizatihî bu sözleşmeye göre iadeyi icabettirmesi halinde gösterilir.” (m. 14, f. 1, bent a).

“Bununla beraber iadeyi talep eden taraf, gerek bu şahsı memleketinden çıkarmak, gerek -gıyap yoluyla muhakeme usulüne müracaat dahil olmak

²³⁰ TANER, sh. 255. Aksi fikir için bkz. DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 588.

²³¹ Aksi fikir için bkz. DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 589; ÖZGEN, sh.156.

üzere- mevzuatına göre mürruzamanı kesmek gayesiyle lüzumlu göreceği diğer tedbirleri ittihaz edebilir.” (m. 14, f. 2).

Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının tümünde iade eden devletin muvafakatının alınması durumunda özellik kuralının etkisinin ortadan kalkacağı hüküm altına alınmıştır.

2) İade Edilen Kişinin Rıza Göstermesi

İade edilen kişi, talepten önce belirtilmeyen suçlar nedeniyle veya iadesine neden olan suçun daha sonradan iadeye elverişli bir suç olmadığı anlaşıldığında bu suç nedeniyle iade edilen devlette yargılanmasına rıza göstermiş olabilir.

Kanaatimizce, kişinin rıza göstermesi, özellik kuralının etkisini ortadan kaldırmaz. Özellik kuralı, sadece iade edilen kişinin haklarını korumak amacıyla kabul edilmiş bir kural olmayıp, iade eden devletin egemenlik hakkını da yakından ilgilendirmektedir. İade iki devlet arasında, kişinin katılmadığı bir anlaşmadır. Kişi iradesi ile, tarafı olmadığı, konusunu teşkil ettiği bir anlaşmayı değiştiremez, bozamaz²³². Keza, kişinin bu konuda açıklayacağı rızanın irade serbestisine dayalı olup olmaması da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, gerek SİDAS’da ve gerekse Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarında bu konuda herhangi bir hükme yer verilmeyerek, iade edilen kişinin rızasına özellik kuralının etkisini ortadan kaldıracı bir değer tanınmamıştır.

3) Belirli Bir Sürenin Geçmesine Rağmen Ülkenin Terk Edilmemesi veya Tekrar Geri Gelinmesi

Gerek SİDAS’da (m. 14, f. 1, bent b) gerek Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarında, iade edilen kişinin, yargılamanın bittiği veya cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren belirli bir sürenin geçmesine rağmen iade edilen devleti terk etmemesi durumunda, iade işleminden önce işlediği suçlardan dolayı da iade edilen devlette yargılabileceği kabul edilmiştir. Ancak kişinin söz konusu devlet ülkesini fiilen terk edebilecek imkana sahip olması gerekir. Nitekim, iade anlaşmalarında elinde imkân olduğu takdirde ülkeyi terk etmemesi durumunda özellik kuralının etkisinin ortadan kalkacağı kabul edilmiştir.

Ayrıca, kişi, anlaşmalarda belirtilen süre içinde iade edilen ülkeyi terk etmesine rağmen, sonradan tekrar aynı devlet ülkesine döndüğünde özellik kuralının etkisini yitireceği kabul edilmiştir.

4) Üçüncü Bir Devlete Yeniden İade

Özellik kuralının iade edilen kişinin, iadedden önce işlediği başka bir suç nedeniyle iade edilen devlet tarafından bir üçüncü devlete tekrar iade edilmesine engel olduğu genellikle kabul edilmektedir²³³.

²³² Nitekim bkz. DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 590.

²³³ TANER, sh. 256; DÖNMEZER/ERMAN III, sh. 591; ÖZGEN, sh. 158.

SİDAS’a göre,

“14’üncü maddenin birinci paragrafının (b) bendinde derpiş edilen hal (yani yargılamanın bittiği veya cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren 45 gün içinde ülkenin terk edilmemesi veya tekrar geri dönülmesi durumu) müstesna olmak üzere, talebeden tarafın kendisine teslim edilip de diğer bir taraf veya üçüncü bir devlet tarafından iadeye mukaddem suçlardan dolayı istenen şahsı bu tarafa veya üçüncü devlete teslim edilmesi için kendisinden iade talep edilmiş olan tarafın rızasını lahik olmak lazımdır. Kendisinden iade talep edilen taraf 12’nci maddenin 2’nci paragrafında mezkûr belgeleri isteyebilir.” (m. 15).

Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmaların tümünde aynı kural benimsenmiştir.

D. İade Edilen Kişinin Yargılanması ve Yargılama Sonucu Hakkında İade Eden Devlete Bilgi Verilmesi

Belli bir suçtan şüpheli veya sanık statüsünde olan kişi, iade edilen devlet yargı organları önünde yargılanacaktır. Bu yargılama tabî hakim önünde ve genel yargılama usullerine uyularak yapılacaktır.

Türkiye’nin taraf olduğu iade anlaşmalarının bazılarında, iade edilen devletin, yargılamanın sonucu ile ilgili olarak iade eden devlete bilgi vermesi yükümlülüğü kabul etmiştir. Yapılan yargılama sonucunda bir cezaya hükmedilmişse, kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı bir örneğinin iade eden tarafa gönderilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

XIII. Milletlerarası Ceza Hukuku Sorunu Olarak, İade Alanında “Male Captus, Bene Detentus” Prensibi

Yukarıdan beri izah etmeye çalıştığımız iade prosedürüne uyulmaksızın, şüpheli, sanık veya hükümlünün, bulunduğu ülkeden bu ülke devletinin zımnî “rızasıyla” veya rızası hilafına getirilerek, hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının veya hükmolunan cezanın infazının hukukiliğini konu alan “**male captus, bene detentus**” kuralının geçerliliği günümüz hukukunda sorgulanırken, ülkemiz uygulamasında iade hukuku ile ilgili dikkat çeken bazı olaylara muttali olmuş bulunmaktayız.

“FETÖ” olarak isimlendirilen yapıyla irtibatlı olduğu ve dolayısıyla, “terör örgütü” üyesi olduğu kabul edilen çok sayıda kişi, iade hukukuna ilişkin milletlerarası hukuk metinlerine, anlaşma hükümlerine riayet edilmeksizin, bulundukları ülkelerden Türkiye’ye getirilmiş ve tutuklanmıştır.

Bu kişilerin getirildiği ülke devletleri ile Türkiye arasında halen yürürlükte olan iki veya çok taraflı iade anlaşmaları bulunmaktadır.

Bu kişilerden bir kısmı, Türk hükümetinin iade hukukuna ilişkin milletlerarası hukuk kuralları ile telifi kabil olmayan talepleri üzerine, bulundukları ülke devleti tarafından sınır dışı edilerek, Türk istihbarat ve emniyet yetkililerine teslim edilmiştir.

Bazı kişiler, Türk istihbarat ve emniyet yetkilileri tarafından, görünüşe göre, bulundukları ülke devletinin bilgisi dışında, “paketlenerek” Türkiye’ye getirilmiştir.

Bir olayda ise bir kişi, Türk istihbarat ve emniyet yetkilileri tarafından, yine görünüşe göre, bulunduğu ülke devletinin bilgisi dışında, “paketlenerek” Türkiye’ye getirilmeye çalışılmıştır. Ancak, ilgili devlet kamu otoritelerinin müdahalesiyle bu girişim başarısız olmuştur.

Bütün bu olaylarda “terör örgütü” ile ilişkileri bulunduğu şüphesiyle Türkiye’de haklarında soruşturma yapılan kişiler mevcuttur. Ancak söz konusu anlaşmalar çerçevesinde bu kişilerin bulundukları ülkeden Türkiye’ye iadesine yönelik süreç işletilmemiştir. Başka bir ifadeyle bu kişiler, milletlerarası ceza hukuku kurallarının dışına çıkılarak Türkiye’ye getirilmişlerdir veya getirilmeye çalışılmıştır. Bütün bu olayların ortak bir özelliği bulunmaktadır. Bu kişiler, gerçekte, haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılmak üzere, bulundukları ülke devletinin açık veya zımni muvafakatiyle Türkiye’ye getirilmişlerdir veya getirilmeye çalışılmıştır.

Bu devletlerin açık veya zımni muvafakati bulunduğu için, iade anlaşmaları hükümleri bir kenara itilerek Türkiye’ye getirilmiş olsalar bile, bu kişiler hakkında Türkiye’de soruşturma ve kovuşturma yapılmasına hukuki bir engel bulunmamaktadır. Abdullah Öcalan’ın Kenya’dan Türkiye’ye getirilmesi ve yargılanarak cezaya mahkûm edilmesi, bu bakımdan bir örnektir.

Ancak, kişi, bulunduğu yabancı ülke devletinin muvafakati olmadan, herhangi bir şekilde “paketlenerek” Türkiye’ye getirilmiş ise, bu yabancı devlete rağmen, Türkiye’de herhangi bir suç sebebiyle soruşturulamaz ve kovuşturulamaz. Bu durumda kişi hangi devletten getirilmişse bu devlete teslim edilerek, Türkiye ile bu devlet arasında usulüne uygun iade prosedürünün işletilmesi gerekir. Aksi uygulama, milletlerarası hukuk bakımından bir sorun oluşturur.

Getirildiği devletin kişinin Türkiye’den kendisine teslim edilmesini istemesine rağmen, bu isteğe olumlu cevap verilmemesi, milletlerarası ceza hukuku uygulamalarında Türkiye’nin hukuk kurallarına sadık kalmadığı yönünde uluslararası camiada bir yargının oluşmasına sebebiyet verir. Bu örnekler gerekçe gösterilerek, Türkiye’nin çeşitli suçlar sebebiyle haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılmak üzere ya da mahkûm oldukları cezaların infazı amacıyla kişilerle ilgili olarak başka devletlerden bulunduğu veya bulunacağı iade taleplerine olumlu cevap verilmekten imtina edilecektir. Hatta, iade talebinin sebebini oluşturan

suç, iade edilebilecek bir suç olmasına rağmen, Türkiye'nin milletlerarası ceza hukuku kurallarına ve özellikle insan haklarına riayet etmesi hususunda milletlerarası camiada taşınan endişeler sebebiyle, vaki talepler kabul görmeyecektir. 15 Temmuz 2016 tarihli “darbe” teşebbüsüne iştirak ettikleri için haklarında soruşturma yapılan askerler, bilahare kaçarak sığınma talebinde bulundukları Yunanistan tarafından bu gerekçeyle Türkiye'ye iade edilmemişlerdir²³⁴. Oysa, iade talebinin sebebini oluşturan söz konusu suç (“darbe” teşebbüsü) bakımından, Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve bu Sözleşmeye ek Protokoller hükümlerine göre iade engeli bulunmamaktadır. Hatırlatmak gerekir ki, 15 Temmuz 2016 tarihli “darbe” teşebbüsüne iştirakleri sebebiyle çeşitli devletlerden iadesi talep edilen kişilerden hiçbirisi henüz Türkiye'ye iade edilmiş değildir.

Milletlerarası ceza hukuku kurallarına ve özellikle insan haklarına riayet konusunda taşınan endişeler sebebiyle iade taleplerinin reddedilmesi, Türkiye'nin, Rusya'nın özellikle Türkiye'de ve çeşitli Arap ülkelerinde bulunan Çeçen direnişçilerin ya da İran'ın çeşitli ülkelere kaçan rejim muhalifi kişilerin bulundukları ülkede infazı yöntemine başvurmasını akla getirebilir. Hatırlatmak gerekir ki, **İsrail**, bu yönteme en fazla başvurmuş ve başvuran bir **haydut** “devlet”tir²³⁵.

²³⁴ Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Suç Örgütleri (14), sh. 96 vd.

²³⁵ İsrail istihbarat servisi, Almanya'da Yahudilere karşı soykırım yapmakla itham edilen Otto Adolf Eichmann'ı, 1960 yılında, bulunduğu Arjantin'den, bu ülke kamu makamlarının bilgisi ve rızası dışında “paketleyerek”, yargılanmak üzere İsrail'e getirir.

Arjantin ile İsrail arasında bu nedenle bir sorun çıkmasına ve sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündemine taşınmasına rağmen; İsrail, Eichmann'ı Arjantin'e teslim etmez. Arjantin'in bilahare verdiği zımnı “muafakat”e dayalı olarak, Eichmann İsrail'de yargılanır ve cezaya mahkum edilir.

Bu olayla ilgili olarak milletlerarası ceza hukuku alanında birçok sorun tartışılır.

Bunlardan birincisi, İsrail'in, kendi ülkesi dışında, kendi vatandaşı olmayan bir kişi tarafından, yine kendi vatandaşı olmayan kişilere karşı işlediği iddia edilen soykırım suçundan dolayı yargılama yetkisini haiz olup olmadığı sorunudur.

İkinci olarak, Eichmann'ın işlediği iddia edilen fiiller, işlendikleri tarih itibarıyla kasten öldürme suçu gibi kanunlarda tanımlanan birtakım suçları oluşturmakla birlikte, henüz soykırım suçu olarak, insanlığa karşı suç olarak tanımlanmış değildir. Söz konusu fiiller, bilahare yapılan kanuni düzenlemeyle soykırım suçu olarak, insanlığa karşı suç olarak tanımlanmış olsa bile, maddi ceza hukukundaki zaman bakımından uygulama kuralları gereğince, adı geçen kişi hakkında bu suçlardan dolayı mahkumiyet hükmü kurulamaz. Buna rağmen, başka bir devletin ülkesinde işlediği iddia edilen söz konusu fiiller sebebiyle, evrensellik ilkesi gereğince, kişi hakkında ülkesinde bulunduğu ve fakat vatandaşı olmadığı bir devlette yargılama yapıp yapılamayacağı ikinci bir sorun olarak değerlendirilebilir. Ancak İsrail, bu soruna rağmen, Eichmann'ı söz konusu fiiller sebebiyle yargılama “yetki”sinin kendisinde görmüş ve adı geçen kişiyi yargılayarak cezaya mahkum etmiştir.

Başka bir sorun, Eichmann'ın, bulunduğu Arjantin'den bu ülkenin kamu makamlarının bilgisi ve rızası dışında “paketlenerek” İsrail'e götürülmüş olması karşısında, Arjantin hükümetinin muafakati olmadan İsrail'de yargılanmasının hukuka uygun olup olmadığı sorunudur.

İsrail’i bu konuda örnek alan diğer önemli bir devlet ise, Amerika Birleşik Devletleridir²³⁶.

Dikkat edilmelidir ki, söz konusu olayda Eichmann’ın “paketlenerek” götürüldüğü sırada, Arjantin kamu makamları durumdan haberdar değildir. Ancak, Arjantin makamları, Eichmann’ın kendisine isnat edilen fiiller sebebiyle İsrail’de yargılanmasına bilahare “muvafakat” etmiştir; daha doğrusu, “muvafakat” etmeye mecbur edilmiştir.

²³⁶ Türkiye’nin **Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri** gibi pek çok devletle arasında suçluların iadesine ilişkin **anlaşma bulunmamaktadır**. Türkiye’de hakkında soruşturma başlatılan kişiler bu ülkelere kaçarak, başlatılan soruşturmanın sonuçlanmasını en azından geciktirebilmektedirler. Ya da, örneğin Latin Amerika ülkelerine kaçan kişiler, başta savunma hakkı olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerini koruma mekanizmalarından yararlanmadan, salt obje durumuna irca edilerek, kolluk zoruyla, “paketleme” veya “karga tulumba” yöntemiyle Türkiye’ye getirilebilmektedir. Bu uygulamaların HUKUK DEVLETİ ilkesiyle bağdaşmadığını belirtmekle yetinmek isterim. Bu bağlamda ilk yapılması gereken iş, Türkiye ile, başta halkı Müslüman olan ülkeler olmak üzere, çeşitli devletler arasında **kişi hak ve hürriyetlerinin güvence altına alındığı hukuk mekanizmaları ile donatılmış iade anlaşmalarının** bir an önce yürürlüğe konmasıdır.

Türkiye ile arasında iade anlaşması mevcut bir devlette bulunan bir kişinin bu anlaşma hükümleri dikkate alınmadan, “paketleme” yöntemiyle Türkiye’ye getirip hürriyetinden yoksun bırakılması halinde, HUKUKA AYKIRI bir iş, işlem yapıldığı, izahtan varestedir.

Ancak, bu durumda asıl sorun, kişinin bulunduğu ülke devletinin Türkiye’nin bu hukuk dışı uygulaması karşısında duyarsız kalması, gerekli hukuk mekanizmalarını harekete geçirmemesi ve hatta, zımnî muvafakatının olmasıdır.

Yararlanılan Kaynaklar

- ACHENBACH**, Hans: *Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystema-tischen Schuldlehre*, Berlin, 1974.
- ACHENBACH**, Hans: Individuelle Zurechnung, Verantwortlichkeit, Schuld, in: Grundfragen des modernen Strafrechtssystems (Hrsg.: Bernd Schünemann), Berlin, 1984, sh. 135 vd.
- AKBULUT**, Berrin: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 5. Bası, Ankara, Eylül 2018.
- AKINCI**, Füsun Sokullu: *Kriminoloji*, İkinci bası, İstanbul, 1999.
- AKTAŞ**, Sururi: *Cezalandırmanın Amacı*, in: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XIII, sayı 1-2, Haziran 2009, sh. 1 vd.
- ALACAKAPTAN**, Uğur: *Suçun Unsurları*, Ankara, 1970.
- ALPASLAN**, M. Şükrü: *Kriminoloji ve Hukuk Açısından Tedhişçilik*, İstanbul, 1983.
- ALTUĞ**, Yılmaz: *Yabancıların Hukuki Durumu*, İstanbul, 1971.
- ANAYURT**, Ömer: *Anayasa Hukuku Genel Kısım (Temel İlkeler, Kavram ve Kurumlar)*, Ankara, Eylül 2018.
- ARAL**, Vecdi: *Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine*, 6. bası, İstanbul, 1991.
- ARMAOĞLU**, Fahir Hadi: *Belçika Kaidesi ve Siyasal Suçluların İadesi Meselesi*, in: Adalet Dergisi, 1951, sh. 1596.
- ARTUK**, Emin: *Ceza Hukukuna Giriş (Ders Notları)*, İstanbul, 1983.
- ARTUK**, Mehmet Emin: *Suç Genel Teorisi*, in: Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul, 1989, sh. 191 vd.
- ARTUK**, M. Emin: *Mukayeseli Çocuk Muhakemesi Hukuku* (yayınlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul, 1987.
- ARTUK**, M. Emin: *Emniyet Tedbirleri*, in: Argumentum, 23(1992), sh. 355.
- ARTUK**, Mehmet Emin: *Hürriyeti Tahdit Cürmü*, in: Halid Kemal Elbir'e Armağan, İstanbul, 1996, sh. 48 vd.
- ARTUK**, Mehmet Emin: *Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümlerine İlişkin Düşünceler*, in: Legal Hukuk Dergisi, yıl 3, sayı 32, Ağustos 2005, sh. 2759 vd.
- ARTUK**, Mehmet Emin: *Yeni Türk Ceza Kanununun Genel Hükümlerine İlişkin Düşünceler*, in: in: Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, Türk Ceza Hukuku Derneği yayını, Yayın No. 7, sh. 23 vd.
- ARTUK**, Mehmet Emin: *Ceza Kanununun Suç Siyaseti Bilimi Açısından Değerlendirilmesi*, in: Ceza Hukuku Dergisi, yıl 1, sayı 2, Aralık 2006, sh. 9 vd.
- ARTUK**, Mehmet Emin/**YENİDÜNYA**, Caner: *Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Erteleme Müessesesi*, in: Prof. Dr. Sahir Erman'a Armağan, İstanbul, 1999, sh. 55 vd.
- ARTUK**, Mehmet Emin/**ÇINAR**, Ali Rıza: *Yeni Bir Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Alt Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2004, sh. 37 vd.
- ARTUK**, Mehmet Emin/**GÖKCEN**, Ahmet/**YENİDÜNYA**, A. Caner: *Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku*, 7. bası, Ankara, 2013.

- ARTUK, M. Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim:** *Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku*, 13. bası, Ankara, 2019.
- ARTUK, M. Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner:** *Ceza Hukuku Özel Hükümler*, Ankara, 1998.
- AŞÇIOĞLU, Çetin.** *Tıbbî Yardım ve El Atmalarından Doğan Sorumluluklar*, Ankara 1993.
- ATALAY, Osman:** *İnfaz Hukuku ve İlamların İnfazı*, Ankara, 2015.
- ATEŞ, Toktamış:** *Demokrasi -Kavram, Tarihî Süreç, İlkeler-*, 3. bası, Ankara, 1994.
- AVCI, Mustafa:** *Örgütlü Suç Kavramı*, in: Kamu Hukuku Arşivi (KHuKA), Mart 2003, yıl 6.
- AYDIN Murat:** *Türkiye’de Çocuk Mahkemeleri Kurulmalıdır!*, in: Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Çocuk(ça) Adalet?, 13-19 Eylül 2013, Tebliğler, Editör Adem Sözüer, sh. 51 vd.
- BAKICI, Sedat:** *5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri*, Ankara, 2007.
- BALO, Yusuf Solmaz:** *Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması*, Ankara, 2005.
- BAUMANN, Jürjen:** *Täterschaft und Teilnahme*, in: JuS 1963, sh. 51 vd. (ayrıca, in: BAUMANN, Beiträge zur Strafrechtsdogmatik, Bielefeld, 1987, sh. 156 vd.).
- BAUMANN, Jürgen/WEBER, Ulrich:** *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 9. Auflage, Bielefeld, 1985.
- BAUMANN, Jürgen/WEBER, Ulrich//MITSCH, Wolfgang:** *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch*, 10. Auflage, Bielefeld, 1995.
- BAYRAKTAR, Köksal:** *Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu*, İstanbul, 1972.
- BAYRAKTAR, Köksal:** *Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü*, İstanbul, 1977.
- BAYRAKTAR, Köksal:** *Siyasal Suç*, İstanbul, 1982.
- BAYRAKTAR, Köksal:** *Faal Nedamet*, İÜHF, cilt XXXIII, sayı 3-4, sh. 138 vd.
- BAYRAKTAR, Köksal:** *İftira*, İÜHF, yıl 1974, cilt XL, sayı. 1-4, sh. 201 vd.
- BAYRAKTAR, Köksal:** *Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılması ve Nakli Hakkında Kanun’a İlişkin Düşünceler*, in: Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, İstanbul 1979, sh.15 vd.
- BAYRAKTAR, Köksal:** *Ceza Kanunundaki Hukuka Uygunluk Nedenleri*, in: Ceza Hukuku Günleri - 70. Yılında Türk Ceza Kanunu - Genel Hükümler- (26-27 Mart 1997) İstanbul 1998.
- BAYRAKTAR, Köksal:** *Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Genel Bir Değerlendirme ve Genel Hükümler Üzerine Birkaç Eleştiri*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap (Türkiye Barolar Birliği Yayını), Ankara, Eylül 2004, sh. 21 vd.
- BAYRAKTAR, Köksal:** *Kolluğun Silah Kullanma Yetkisinin Yasal Dayanakları*, in: Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, İstanbul 2005, sh. 27 vd.
- BAYTEMİR KONTACI, Burcu:** *Suçluların Geri Verilmesinde Yeni Arayışlar: Geri Vermede Basitleştirilmiş Usul*, in: Dr.Dr.h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Editörler: F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoğlu, A. Sözüer, F. Turhan, Ankara, Mayıs 2018, sh. 1097 vd.
- BAYTEMİR KONTACI, Burcu:** *Ceza Hukukunun Uluslararasılaşması ve Ulusal Ceza Hukuku Sistemleri: Türk Ceza Hukuku Özelinde Bir İnceleme*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019.

- BEHRENDT**, Hans-Joachim: *Affekt und Vorverschulden. Eine Untersuchung zur strafrechtlichen Differenzierung von Struktur und Funktion menschlicher Selbststeuerung*, Baden-Baden, 1983.
- BELING**, Ernst: *Die Lehre vom Verbrechen*, Tübingen, 1906 (Neudruck: Aalen, 1964).
- BELING**, Ernst: *Grundzüge des Strafrechts*, 3. Auflage, Tübingen, 1905; 11. Auflage, Tübingen, 1930.
- BENDA**, Ernst: *Die Menschenwürde*, in: Benda/Maihofer/Vogel, Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin-New York, 1983.
- BINDING**, Karl: *Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die Rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts*, Band I (Normen und Strafgesetze), 1. Auflage, Leipzig, 1872.
- BINDING**, Karl: *Die Normen und ihre Übertretung*, Band II (Schuld und Vorsatz), 1. Auflage, Leipzig, 1877.
- BINDING**, Karl: *Die Normen und ihre Übertretung*, Band III (Der Irrtum), Leipzig, 1918.
- BLAUTH**, Peter: *"Handeln für einen anderen" nach geltendem und kommendem Strafrecht*, Heidelberg, 1968.
- BLEI**, Hermann: *Strafrecht I, Allgemeiner Teil*, 17. Auflage, München, 1977; 18. Auflage, München, 1983.
- BLOY**, René: *Finaler und sazialer Handlungsbegriff*, in: ZStW 90(1978), sh. 609 vd.
- BOCKELMANN**, Paul: *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 3. Auflage, München, 1979.
- BOCKELMANN**, Paul: *Über das Verhältnis von Täterschaft und Teilnahme*, Göttingen, 1949 (ayrıca, in: Bockelmann, Strafrechtliche Untersuchungen, Göttingen, 1957, sh. 31 vd.
- BOCKELMANN**, Paul: *Vom Sinn der Strafe*, in: Heidelberger Jahrbücher, Band V, Heidelberg, 1961.
- BOCKELMANN**, Paul/**VOLK**, Klaus: *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, München, 1987.
- BOZBAYINDIR**, Ali Emrah: *Kanunilik İlkesi ve Özel Ceza Kanunları*, İstanbul, Aralık 2013.
- BOZBAYINDIR**, Ali Emrah: *Türk ve Mukayeseli Ceza Hukukunda Olası Kast Kavramı ve Sınırları*, Ankara, Ekim 2018.
- v.BURI**, Maximilian: *Über Causalitaet und deren Verantwortung*, Leipzig, 1873.
- v.BURI**, Maximilian: *Die Causalitaet und ihre strafrechtliche Beziehung*, 1885.
- CENTEL**, Fatma Nur: *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, İstanbul, Kasım 2001.
- CENTEL**, Fatma Nur/**ZAFER**, Hamide/**ÇAKMUT**, Özlem: *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, 3. bası, İstanbul, Ekim 2005.
- CENTEL**, Fatma Nur/**ZAFER**, Hamide/**ÇAKMUT**, Özlem: *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, 4. bası, İstanbul, Ekim 2006.
- CENTEL**, Fatma Nur/**ZAFER**, Hamide/**ÇAKMUT**, Özlem: *Türk Ceza Hukukuna Giriş*, 5. bası, İstanbul, 2008.
- CENTEL**, Fatma Nur: *Şartla Salıverme*, in: Hukuk Araştırmaları, cilt 7, yıl 1992-1993, sayı 1-3, sh. 43.

- CENTEL**, Fatma Nur: *Yeni Türk Ceza Kanununda Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri Sistemi*, in: in: Yeni Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, 5 Mart 2005, Türk Ceza Hukuku Derneği yayını, Yayın No. 7, sh. 53 vd.
- ÇİHAN**, Erol: *Cebir Kullanma Cürmü*, İstanbul, 1978.
- ÇAĞIL**, Orhan Münir: *Hukuk Metodolojisi Dersleri*, 3. bası, İstanbul, 1962.
- ÇAĞLAYAN**, Muhtar: *Türk Ceza Kanunu*, cilt I, 3. bası, Ankara, 1984.
- ÇAĞLAYAN**, Muhtar: *Türk Ceza Kanunu*, cilt IV, 3. bası, Ankara (tarih yok).
- ÇAKMUT**, Özlem Yenerer: *Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi*, İstanbul 2003.
- ÇELİK**, Edip: *Devletler Hukukunda Diplomatik Melce ve Milletlerarası Adalet Divanı İçtihadı*, İstanbul, 1956.
- ÇELİKEL**, Aysel: *Yabancılar Hukuku Dersleri*, İstanbul, 1983.
- ÇETİN**, Soner Hamza: *Türk Ceza Kanununda Seçenek Yaptırımlar*, Ankara, 2011.
- ÇETİN**, Soner Hamza: *Türk Ceza Kanununda Adli Para Cezası*, Ankara, 2012.
- ÇETİN**, Soner Hamza: *Türk Ceza Hukukunda Yorum ve Kıyas*, Ankara, 2014.
- ÇINAR**, Ali Rıza: *Türk Ceza Hukukunda Cezalar*, Ankara, 2005.
- ÇINAR**, İsmail: *Ceza Hukukunda Ön Kusurluluk*, Ankara 2024.
- ÇINAR**, İsmail: *Ceza Hukukunda Değerlendirme Hatası*, in: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 5, sayı 2, Aralık 2023, sh. 623 vd.
- ÇINAR**, İsmail: “Ceza Kanunlarını Bilmemek Mazeret Sayılmaz” Mı?, in: Legal Hukuk Dergisi, cilt 19, sayı 226, Ekim 2021, sh. 4515 vd.
- ÇINAR**, İsmail: *Atılma Hatası’nın (Der Subsumtionsirrtum) Kavramsal ve Hukuki Anlamı*, in: Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 6, Temmuz 2021, sh. 79 vd.
- ÇOBANOĞLU**, Rahmi: *Hukukta Gaye Problemi*, İstanbul, 1964.
- DEMİRBAŞ**, Timur: *Türk Ceza Kanununda Özel Haksız Tahrik Halleri*, İstanbul 1985.
- DEMİRBAŞ**, Timur: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, Ankara, 2002.
- DEMİRBAŞ**, Timur: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 6. bası, Ankara, 2009.
- DEMİRBAŞ**, Timur: *Kriminoloji*, Ankara, 2001.
- DEMİRBAŞ**, Timur: *Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması*, in: Hayri Domaniç’e Armağan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını), İstanbul 1995, sh. 277 vd.
- DEMİREL**, Muhammed: *Çifte Özen Anlayışı Çerçevesinde Taksirli Suçtan Doğan Ceza Sorumluluğu*, Ankara, Mart 2022.
- DEMİREL**, Muhammed: *Suçta İştirakte Bağlılık Kuralı*, İstanbul, Aralık 2017.
- DEMİRTAŞ**, Soner: *Tehlike Suçları*, Ankara, 2023.
- DEMİRTAŞ**, Soner: *Die Konkurrenzlehre im deutschen und türkischen Strafrecht*, Berlin, 2016.
- DEMİRTAŞ**, Soner: *Suçun Nitelikli Hallerine Teşebbüs*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXV, yıl 2021, sayı 3, sh. 379 vd.
- DENETİMLİ SERBESTLİK ve Yardım Hizmetleri El Kitabı** (Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevki-fevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı yayını), Ankara 2006
- DİNÇMEN**, Kriton: *Adli Psikiyatri*, İstanbul, 1984.

- DİNÇMEN**, Kriton: *Bir Adli Tıp Bilmecesi: Epilepsi*, in: II Ulusal Adli Tıp Günleri (25-28 Eylül 1985-Bursa) Panel ve Serbest Bildirileri, İstanbul 1986, sh. 104 vd.
- DOĞAN**, Koray: *Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar*, Ankara, 2011.
- DOĞANAY**, Ümit Yaşar: *Das Türkische Auslieferungsrecht*, (Doktora Tezi), Freiburg i. Br., 1956.
- DÖNMEZER**, Sulhi: *Cezai Mesuliyetin Esası*, İstanbul, 1949.
- DÖNMEZER**, Sulhi: *Ceza Hukuku, Özel Kısım, Genel Adab ve Aile Düzenine Karşı Cürümler*, 5. bası, İstanbul, 1983.
- DÖNMEZER**, Sulhi: *Kişilere ve Mala Karşı Cürümler*, 13. bası, İstanbul, 1990.
- DÖNMEZER**, Sulhi: *Kriminoloji*, 8. bası, İstanbul, 1994.
- DÖNMEZER**, Sulhi: *Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi ve İnsan Hakları*, in: Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, İstanbul 2005, sh. 9 vd.
- DÖNMEZER**, Sulhi: *Mukayeseli Hukukta Yasalaştırma Eğilimi ve İlkeleri*, in: Atatürk'ün 100. Doğum Yıldönümü Kutlama Çalışmaları, Kolokyumlar ve Tartışmalar (14 Ocak 1981), (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını), sh. 16.
- DÖNMEZER**, Sulhi: *Yabancı Memlekette İşlenen Suçlar, Siyasî Suçlar ve Nisbî Siyasî Suçlar*, in: İÜHFM, cilt XV, yıl 1949, sh.760 vd.
- DÖNMEZER**, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku*, cilt I, 12. bası, İstanbul, Ocak 1997.
- DÖNMEZER**, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku*, Cilt II, 10. bası, İstanbul, Mayıs 1994.
- DÖNMEZER**, Sulhi/ERMAN, Sahir: *Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku*, cilt III, 11. bası, İstanbul, Eylül 1994.
- DREHER**, Eduard: *Die Willensfreiheit*, München, 1987.
- DURAN**, Lutfi: *Türkiye Hükümetinin Suçluların İadesine Dair Kararları Üzerinde Kazai Murakabe*, in: Tahir Taner'e Armağan, İstanbul, 1956, sh. 609.
- DURSUN**, Selman/**BOZBAYINDIR**, Ali Emrah: *Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Manevi Unsurları Meselesi*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LXXIII, yıl 2015, sayı 1, sh. 63 vd.
- EKİCİ ŞAHİN**, Meral: *Ceza Hukukunda Rıza*, İstanbul, Ocak 2012.
- EKŞİ**, Nuray: *Mahkeme Kararları Işığında Suçluların İltica Sistemi Dışında Bırakılması*, İstanbul, Kasım 2017.
- ENGISCH**, Karl: *Der finale Hadlugsbegriff*, in: Probleme der Strafrechtserneuerung, Festschrift für Eduard Kohlrausch, Berlin, 1944, sh. 141 vd.
- ENGISCH**, Karl: *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht*, Berlin, 1930 (Neudruck: Aalen, 1964).
- ERBAŞ**, Rahime: *Türk Ceza Kanunu'nda Görünüşte İhmali Suçlarda Garantörlük*, İstanbul 2019.
- ERDAĞ**, Ali İhsan: *Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç (Erfolgsqualifiziertes Delikt)*, Ankara, Nisan 2011.
- ERDEM**, Mustafa Ruhan: *Yeni TCK'da Failik ve Suç Ortaklığı*, in: Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD), sayı 5, Aralık 2005.
- ERDURAK**, Yılmaz Güngör: *Notlu İçtihatlı Türk Ceza Kanunu*, 3. bası, Ankara, Ocak, 1994.

- EREM**, Faruk: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler*, cilt I, Ankara, 1973.
- EREM**, Faruk: *Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, cilt I, 12. bası, Ankara, 1984.
- EREM**, Faruk: *Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, cilt II, 12. bası, Ankara 1985.
- EREM**, Faruk: *Diyalektik Açısından Ceza Yargılaması Hukuku*, 6. bası, Ankara, 1986.
- EREM**, Faruk: *Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi*, 10. bası, Ankara, 1997.
- EREM**, Faruk/**DANIŞMAN**, Ahmet/**ARTUK**, Mehmet Emin: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 14. bası, Ankara, 1997.
- EREM**, Faruk: *Ceza Hukukunda Hukuku Bilmeme ve Yanılma*, İÜHF 12(1946), sh. 531.
- EREM**, Faruk: *Tekerrürün Esası*, in: Adalet Dergisi, sayı 10, yıl 1949, sh. 1417 vd.
- ERGÜL**, Ergin: *Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli*, Ankara, 2003.
- ERMAN**, Ragıp Barış: *Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu*, Ankara, 2003.
- ERMAN**, Ragıp Barış: *Yanılganın Ceza Sorumluluğuna Etkisi*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006.
- ERMAN**, Sahir: *Sahtekârlık Suçları*, 4. bası, İstanbul, 1981.
- ERMAN**, Sahir: *Askeri Ceza Hukuku, Umumi Kısım ve Usul*, 7. bası, İstanbul, 1983.
- ERMAN**, Sahir: *Ticari Ceza Hukuku I - Genel Kısım*, 5. bası, İstanbul, 1992.
- ERMAN**, Sahir: *Akıl Hastalığı ve Ceza Kanunları*, in: İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü, Akıl Hastalarına Karşı Cemiyetin Müdafaası (Raporlar), İstanbul, 1958, sh. 265 vd.
- ERMAN**, Sahir: *Siyasi İltica Hakkı*, in: Sos. Huk. ve İkt. Mec., Ocak, 1950 sh. 181.
- ERMAN**, Sahir: *Uyuşturucu Maddelere İlişkin Ceza Hükümleri*, in: Atatürk'ün 100. Doğum Yılı-dönümü Kutlama Çalışmaları Kollokyumlar ve Tartışmalar, İstanbul, sh.261.
- ERMAN**, Sahir: Erman/Özek, *Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar*, İstanbul 1994.
- ERMAN**, Sahir: Erman/Özek, *Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar*, İstanbul, 1996.
- ERSAN**, Aykut: *Ceza Hukukunda Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması*, İstanbul 2013.
- FEUERBACH**, Paul Johann Anselm: *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts*, 14. Ausgabe, Gießen, 1847.
- FRANK**, Reinhard: *Über den Aufbau des Schuldbegriffs*, Giessen, 1907.
- FRANK**, Reinhard: *Vollendung und Versuch*, in: Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, Bd. V, Berlin 1908.
- FRISTER**, Helmut: *Die Struktur des "voluntativen Schuldelements". Zugleich eine Analyse des Verhältnisses von Schuld und positiver Generalprävention*, Berlin, 1993.
- GALLAS**, Wilhelm: *Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen*, in: ZStW 67(1955), sh. 1 vd. (ayrıca, GALLAS, Wilhelm: Beiträge zur Verbrechenslehre, Berlin, 1968, sh. 19 vd.).

- GEMALMAZ**, Mehmet Semih: *Türkiye’de Ölüm Cezası*, cilt I, İstanbul, Ocak 2001.
- GOLDSCHMIDT**, James: *Der Notstand, ein Schuldproblem. Mit Rücksicht auf die Strafgesetzentwürfe Deutschlands, Österreichs und der Schweiz*, in: *Österreichische Zeitschrift für Strafrecht*, 1913, sh. 129 vd., ayrıca, sh. 224 vd.
- GOLDSCHMIDT**, James: *Normativer Schuldbegriff*, in: *Beitraege zur Strafrechtswissenschaft*, Festgabe für Reinhard Frank, Band I, Tübingen, 1930, sh. 428 vd.
- GOLDSCHMIDT**, James: *Gegenentwurf zu den Abschnitten “Die Straftat” und “Taeter und Teilnehmer” des Strafgesetzentwurfs von 1919*, in: *JW* 1922, sh. 252 vd.
- GÖKCAN**, Hasan Tahsin: *Türk Ceza Kanunundaki Bazı Genel ve Özel Nitelikli Kamu Görevi Yükümlülük Suçları, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, İrtikap, Rüşvet ve Denetim Görevini İhmali Suçları*, Ankara 2022.
- GÖKCAN**, Hasan Tahsin: *Açıklamalı Avukatlık Yasası, Avukatların Görev Suçları, Özel Soruşturma Usulü, Hukuki Sorumluluk*, 2. bası, Ankara, 2009.
- GÖKCAN**, Hasan Tahsin: *Yargıtay Kararları Işığında Hekimin Ceza Sorumluluğu*, in: Av. Dr. Şükrü Alpaslan Armağanı, sh. 354 vd.
- GÖKCAN**, Hasan Tahsin: *Perinatolojide Tıbbi Uygulama Hataları Nedeniyle Cezai Sorumluluk*, in: 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-29 Nisan 2007, Antalya, sh. 109 vd.
- GÖKCAN**, Hasan Tahsin/**KAYMAZ**, Seydi. *Önödemeğe Bağlı Suçlar*, Ankara (tarih yok).
- GÖKTÜRK**, Neslihan: *Fikri İctima (Suçların İctimai)*, Ankara, 2013.
- GÖKTÜRK**, Neslihan: *Haksızlık Yanılgısının Ceza Sorumluluğuna Etkisi*, Ankara, Aralık 2016
- GÖLCÜKLÜ**, Feyyaz: *Suçta Kanunî Unsurun Ortadan Kalkması, Fiilin Hukuka Aykırılığı ve Hukuka Uygunluk Nedenleri Konusunda Bazı Mülahazalar*, in: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, yıl 1968, cilt XXIII, sh. 187 vd.
- GÖLCÜKLÜ**, Feyyaz: *“İdari Ceza Hukuku” ve Anlamı, İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki*, in: SBFD, cilt XVIII, sayı 2, Ankara, 1963, sh. 123 vd.
- GÖZLER**, Kemal: *Türk Anayasa Hukuku Dersleri*, 5. bası, Bursa, Ocak 2008.
- GÖZLER**, Kemal: *Anayasa Hukukuna Giriş, Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku*, 11. bası, Bursa, Ekim 2007.
- GÖZLER**, Kemal: *Devlet Başkanları*, Bursa 2001.
- GÖZÜBÜYÜK**, A. Pulat: *Devletlerarası Ceza Hukuku*, Ankara, 1959.
- GÖZÜBÜYÜK**, A. Pulat: *Suçluların Geri Verilmesi Hukukunun Birleştirilmesi ve Geriverme Umumi Antlaşma Tasarısı*, Ankara, 1949.
- GRAF ZU DOHNA**, Alexander: *Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 4. Auflage, Bonn, 1950.
- GRAF ZU DOHNA**, Alexander: *Die Elemente des Schuldbegriffs*, in: *GS* 65(1905), sh. 304 vd.
- GRAF ZU DOHNA**, Alexander: *Zur Systematik der Lehre vom Verbrechen*, in: *ZStW* 27(1907), sh. 329 vd.
- GROPP**, Walter. *Alman Bakışına Göre Türk Ceza Kanunu 1989 Öntasarısında Hukuka Uygunluk Sebepleri* (Çeviren: Faruk Turhan), in: *Türk Ceza Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler*, Konya 1998, sh: 205-233.
- GRÜNHUT**, Max: *Grenzen des übergesetzlichen Notstandes*, in: *ZStW* 51(1931), sh. 455 vd.
- GÜLŞEN**, Recep: *Ceza Hukukunda Sorumluluğu Kaldıran Nedenlerden Kaza, Mücbir Sebep, Cebir ve Tehdit*, Ankara 2007.

- GÜNAL**, Yılmaz: *Adli Yolla Memnu Hakların İadesi*, Ankara, 1961.
- GÜNEY**, Niyazi/**ÖZDEMİR**, Kenan/**BALO**, Yusuf Solmaz: *Gerekçe ve Tutanaklarla Karşılaştırmalı Yeni Türk Ceza Kanunu*, Ankara, Kasım 2004.
- GÜRİZ**, Adnan: *Hukuk Felsefesi*, Ankara, 1985.
- HAFIZOĞULLARI**, Zeki: *Ceza Normu, Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni*, Ankara, 1987.
- HAFIZOĞULLARI**, Zeki: *Türk Ceza Hukuku Ders Notları*, in: "<http://www.baskent.edu.tr/~zekih/uygulamaci/cezahukuku.doc>"
- HAFIZOĞULLARI**, Zeki/**ÖZEN**, Muharrem: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 5. bası, Ankara, 2012.
- HAKERİ**, Hakan: *Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmali Suçların Çeşitleri*, Ankara, Şubat 2003.
- HAKERİ**, Hakan: *Kasten Öldürme Suçları*, Ankara, Ocak 2006.
- HAKERİ**, Hakan: *Kasten Öldürme Suçları*, 2. bası, Ankara, Eylül 2007.
- HAKERİ**, Hakan: *Ceza Hukuku*, 5. bası Ankara, Ocak 2007.
- HAKERİ**, Hakan: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 16. bası Ankara, 2013.
- HAKERİ**, Hakan: *Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, 18. bası, Ankara 2015.
- HAKERİ**, Hakan: *Yeni Türk Ceza Kanununda İhmali Suçlar*, in: *Hukuk ve Adalet Dergisi*, yıl 2, sayı 5, Nisan 2005.
- HARDWIG**, Werner: *Die Zurechnung. Ein Zentralproblem des Strafrechts*, Hamburg, 1957.
- HARDWIG**, Werner: *Grundprobleme der Allgemeinen Strafrechtslehre*, Kassel, 1984.
- HARDWIG**, Werner: *Personales Unrecht und Schuld*, in: *MschKrim* 44(1961), sh. 194 vd.
- HATEMİ**, Hüseyin: *Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları*, İstanbul, 1976.
- HEGLER**, August: *Die Merkmale des Verbrechens*, in: *ZStW* 36(1915), sh. 19 vd.
- HEGLER**, August: *Subjektive Rechtswidrigkeitsmomente im Rahmen des allgemeinen Verbrechensbegriffs*, in: *Festgabe für Reinhard von Frank*, Band I, Tübingen, 1930, sh. 251 vd.
- HENKEL**, Heinrich: *Der Notstand nach gegenwaertigem und künftigem Recht*, München, 1932.
- v.HIPPEL**, Robert: *Deutsches Strafrecht, Zweiter Band, Das Verbrechen, Allgemeine Lehren*, Berlin, 1930.
- v.HIPPEL**, Reinhard: *Untersuchungen über den Rücktritt von Versuch*, Berlin 1966.
- HIRSCH**, Hans Joachim: *Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen. Der Irrtum über einen Rechtfertigungsgrund*, Bonn, 1960.
- HORN**, Eckhard: *Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit. Eine systematische Grundlagenanaly-se der Schuldtheorie*, Berlin 1969.
- HORN**, Arnold: *Causalitäts- und Wirkungsbegriff, dessen empirische und kriminalrechtliche Bedeutung*, in: *GS* 54(1897), 321 vd.
- İÇEL**, Kayıhan: *Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk*, İstanbul, 1967.
- İÇEL**, Kayıhan: *Suçların İçtimai, Genel Bilgiler - Fikrî İçtima - Mütessesil Suçlar - Görünüşte İçtima*, İstanbul, 1972.

- İÇEL, Kayıhan. *Kitle Haberleşme Hukuku (Basın, Radyo - Televizyon, Sinema, İnternet)*, 4. bası, İstanbul 1998.
- İÇEL, Kayıhan: *Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Olan Müesseselerdeki Gelişmeler ve Türk Ceza Sisteminin Bu Yönden Değerlendirilmesi*, in: TCK'nın 50 Yılı ve Geleceği Sempozyumu, 22-26 Mart 1976, İstanbul 1977, sh. 321 vd.
- İÇEL, Kayıhan: *Kaçakçılıkta Kullanılan Üçüncü Kişilere Ait Taşıtların Zoralımı*, in: İÜHFM 44(1978), sh. 301 vd.
- İÇEL, Kayıhan: *Sermaye Piyasası Kurulunun Tebliğlerine Aykırılık Suçu*, in: İÜHFM, Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'na Armağan Sayısı, cilt LVI, yıl 1998, sayı 1-4, sh. 113.
- İÇEL, Kayıhan: *Suçluların Geri Verilmesi Üzerine Bir İnceleme*, in: İÜHFM, cilt XXX, sayı 3-4, sh.693.
- İÇEL, Kayıhan: *Non Bis İn İdem Kuralının Milletlerarası Değeri*, in: İÜHFM, cilt XXXVII, sayı 1-4, sh. 402.
- İÇEL, Kayıhan/DONAY, Süheyl: *Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım*, İstanbul, 1987.
- İÇEL, Kayıhan/DONAY Süheyl: *Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I*, 2. bası, İstanbul 1993.
- İÇEL, Kayıhan/DONAY, Süheyl: *Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım*, 1. Kitap, 3. bası, İstanbul, 1999.
- İÇEL, Kayıhan/SOKULLU-AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem/ MAHMUT-TOĞLU, Fatih Selami/ÜNVER, Yener: *Suç Teorisi. Suç Kavramına ilişkin Genel Bilgiler, Suçun Yapısal unsurları, Suçun Özel Oluşum Biçimleri*, 2. Kitap, Yeniden gözden geçirilmiş 3. bası, İstanbul, 2004.
- İÇEL, Kayıhan/SOKULLU-AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem/ MAHMUT-TOĞLU, Fatih Selami/ÜNVER, Yener: *Yaptırım Teorisi*, 3. Kitap, 2. bası, Eylül 2002.
- İÇER, Zafer: *Suçta Teşebbüste Hazırlık Hareketleri ile İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması*, İstanbul, 2021.
- İMRE, Zahit: *Medeni Hukuka Giriş (Temel Kavramlar, Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri ve Hakiki Şahıslar Hukuku)*, 3. bası, İstanbul, 1980.
- İŞOĞLU, Polat: *Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Adli Para Cezası*, Ankara, 2008.
- JAKOBS, Günther: *Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt*, Berlin, 1972.
- JAKOBS, Günther: *Schuld und Prävention*, Tübingen, 1976.
- JAKOBS, Günther: *Strafrecht, Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungs-lehre*, Berlin/New York, 1983.
- JAKOBS, Günther: *Das Schuldprinzip*, Opladen, 1993.
- JAKOBS, Günther: *Strafrechtliche Schuld ohne Willensfreiheit*, in: Aspekte der Freiheit [herausgegeben von Dieter Heinrich], Regensburg, 1982, sh. 69 vd.
- JESCHECK, Hans Heinrich: *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 2. Auflage, Berlin, 1972.
- JESCHECK, Hans Heinrich: *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, Berlin, 1988.
- JESCHECK, Hans Heinrich: *Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş* (Çeviri: Feridun Yenisey; in: Türk Ceza Hukukuna ilişkin Açıklamalar: Kayıhan İçel, Köksal Bayraktar), İstanbul, 1989.

- JESCHECK**, Hans Heinrich: *Der strafrechtliche Handlungsbegriff in dogmengeschichtlich-her Entwicklung*, in: Festschrift für Eberhard Schmidt, Göttingen, 1961, sh. 139 vd.
- JESCHECK**, Hans Heinrich: *Wesen und rechtliche Bedeutung der Beendigung der Straftat*, in: Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag, Berlin-New York 1974, S. 683 vd.
- JESCHECK**, Hans-Heinrich/**WEIGEND**, Thomas. *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 5. Auflage, Berlin 1996.
- KAMER**, Vehbi Kadri: *Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı*, 2. bası, Ankara, 2007.
- KANGAL**, Zeynel T.: *Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu*, Ankara, 2010.
- KANGAL**, Zeynel T.: *Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Objektif ve Sübjektif İsnadiyet*, İstanbul (tarihsiz).
- KANGAL**, Zeynel T.: *Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması*, in: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010/1, cilt I, sh. 785 vd.
- KANGAL**, Zeynel T.: *Cezalandırılabilirliğin Objektif Koşulları*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LXVIII, sayı 1-2, yıl 2010, sh. 151 vd.
- KANGAL**, Zeynel T.: “*Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Gönüllü Vazgeçme*”, in: Beiträge zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht, Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung, Baden-Baden 2010, sh. 335 vd.
- KANGAL**, Zeynel T.: *Kişisel Cezasızlık Nedenleri ve Cezayı Kaldıran Veya Azaltan Kişisel Nedenler*, in: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 2011, c: 7, sy: 85-86, sh. 38 vd.
- KANGAL**, Zeynel T.: *Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik*, in: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XIV, sayı 3-4, Aralık 2010, sh. 19 vd.
- KARAKEHYA**, Hakan: *Olası Kast*, in: Ceza Hukuku Dergisi, yıl 1, sayı 2, Aralık 2006, sh. 19 vd.
- KARAKEHYA**, Hakan: *Ceza Hukukunda Doğrudan Kast*, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 15, yıl 2007, sayı 1, sh. 117 vd.
- KARAKEHYA**, Hakan: *İradilik Unsuru Bağlamında Ceza Hukukunda Kast*, Ankara, 2010.
- KATOĞLU**, Tuğrul: *Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık*, Ankara 2003.
- KATOĞLU**, Tuğrul: *Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması*, Ankara, 2008.
- KAUFMANN**, Armin: *Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, Normlogik und moderne Strafrechtsdogmatik*, Göttingen, 1954 (erweiterter Nachdruck der 1. Auflage: Göttingen, 1988).
- KAUFMANN**, Armin: *Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte*, Göttingen, 1959.
- KAUFMANN**, Armin: *Das fahrlässige Delikt*, in: Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1964, sh. 41 vd.
- KAUFMANN**, Armin: *Tatbestandseinschränkung und Rechtfertigung*: JZ 1955, sh. 37 vd.
- KAUFMANN**, Armin: *Zum Stande der Lehre vom personalen Unrecht*, in: Festschrift für Hans Welzel, Berlin, 1974, sh. 393 vd.
- KAUFMANN**, Arthur: *Das Unrechtsbewußtsein in der Schuldlehre des Strafrechts*, Mainz, 1950.
- KAUFMANN**, Arthur: *Das Schuldprinzip*, Heidelberg, 1961.
- KAUFMANN**, Arthur: *Recht und Sittlichkeit*, Tübingen, 1964.

- KAUFMANN**, Arthur: *Rechtsphilosophie in der Nach-Neuzeit*, 2. Auflage, Heidelberg, 1992.
- KAUFMANN**, Arthur: *Zur Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen*, in: JZ 1954, sh. 653 vd. (ayrıca, KAUFMANN, Schuld und Strafe, Köln/Berlin/Bonn/ München, 1966, sh. 102 vd.).
- KAUFMANN**, Arthur: *Tatbestand, Rechtfertigungsgründe und Irrtum*, in: JZ 1956, sh. 353 vd., 393 vd. (ayrıca, KAUFMANN, Schuld und Strafe, Köln/Berlin/Bonn/ München, 1966, sh. 123 vd.).
- KAUFMANN**, Arthur: *Der Irrtum im Strafgesetz-Entwurf 1962*, in: ZStW 76(1964), sh. 543 vd.
- KAUFMANN**, Arthur: *Dogmatische und kriminalpolitische Aspekte des Schuldgedankens im Strafrecht, ein Beitrag zur Strafrechtsreform*, in: Juristenzeitung, 1967, sh. 553 vd.
- KAUFMANN**, Arthur: *Schuldprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz*, in: Festschrift für Richard Lange, Berlin, 1976, sh. 27 vd.
- KAUFMANN**, Arthur: *Schuld und Prävention*, in: Festschrift für Rudolf Wassermann, Darmstadt/Neuwied, 1985, sh. 889 vd.
- KAUFMANN**, Arthur: *Unzeitgemäße Betrachtungen zum Schuldgrundsatz im Strafrecht*, in: Jura, 1986, sh. 225 vd.
- KAYMAZ**, Seydi: *Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma*, Ankara, 2009.
- KAYMAZ**, Seydi/**GÖKCAN**, Hasan Tahsin: *Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlama ve Önödeme*, Ankara, 2005.
- KEÇELİOĞLU**, Elvan: *Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Sebeplerle Hukuka Uygunluk Sebepleri Arasındaki Ayrımın TCK'nın Uygulanması Bakımından Pratik Sonuçları*, in: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 87, Mart – Nisan 2010, sh. 299 vd.
- KEÇELİOĞLU**, Elvan: *Taksirli Suçun Dogmatigi*, Ankara 2015.
- KERN**, Eduard: *Grade der Rechtswidrigkeit*, in: ZStW 64(1952), sh. 255 vd.
- KESKİN**, O. Kadri: *Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Sebebiyet*, Ankara, 1991.
- KESKİNSOY**, Ömer: *Siyasi Parti Grubu Toplantılarında Sarf Edilen Sözler Bakımından Tazminat Sorumluluğunun Tartışılmasına Dair Yargıtay Kararının Tahlili*, in: Terazi Aylık Hukuk Dergisi, yıl 4, sayı 34, Haziran 2009, sh. 85 vd.
- KIENAPFEL**, Diethelm: *Das erlaubte Risiko in Strafrecht*, Frankfurt am Main 1966.
- KILIÇ**, Ali Şahin: *Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık*, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara 2020.
- KOCA**, Mahmut: *YTCK'da Hukuka Uygunluk Sebepleri*, in: Ceza Hukuku Dergisi, yıl 1, sayı 1, Ekim 2006, sh. 111 vd.
- KOCA**, Mahmut/**BOZKURT**, Özge/**AKAR**, İbrahim: *Çocukların Kendi aralarındaki Cinsel İlişkinin Cezalandırılabilirliği Sorumu*, in: Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan, Ankara, 2020, sh. 633 vd.
- KOCA**, Mahmut/**ÜZÜLMEZ**, İlhan: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku*, 13. bası, Ankara, Eylül 2020.
- KOCA**, Mahmut/**ÜZÜLMEZ**, İlhan: *Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler*, 7. bası, Ankara, Ekim 2020.

- KOHLRAUSCH**, Eduard: *Irrtum und Schuld im Strafrecht*, I. Teil, Berlin, 1903.
- KOHLRAUSCH**, Eduard: *Die Schuld (Vorsatz, Fahrlässigkeit, Rechtsirrtum, Erfolgshaftung)*, in: Die Reform des Reichsstrafgesetzbuchs (Hrsg. von P.F. Aschrott und F.von Liszt), Band I: Allgemeiner Teil, Berlin, 1910, sh. 180 vd.
- KOHLRAUSCH**, Eduard: *Der Allgemeine Teil des Entwurfs 1925*, in: Reform des Strafrechts. Kritische Besprechung des Amtlichen Entwurfs eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs (Hrsg. Aschrott/Kohlrausch), Berlin/Leipzig, 1926, sh. 3 vd.
- KÖK**, Ahmet Nezi: *İnsan Hakları ve Biyotip Sözleşmesine Göre Aydınlatma ve Rıza*, in: Kamu Hukuku Arşivi (KHUKA), Kasım 2005, yıl 8, sh. 116 vd.
- KUNTER**, Nurullah: *Suçun Kanunî Unsurları Nazariyesi*, İstanbul, 1949.
- KUNTER**, Nurullah: *Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi (Hareket - Netice - Sebebiyet Alâkası)*, İstanbul, 1954.
- KUNTER**, Nurullah: *Ceza Hukukunda Zamanaşımı* (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul, 1946.
- KUNTER**, Nurullah: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 9. bası, İstanbul, 1989.
- KUNTER**, Nurullah/**YENİSEY**, Feridun: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 10. bası, İstanbul 1998.
- KUNTER**, Nurullah/**YENİSEY**, Feridun: *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 11. bası, İstanbul 2000.
- KÜHL**, Kristian. *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, München 1994.
- KÜHL**, Kristian: *Die Beendigung des vorsätzlichen Begehungsdelikts*, Berlin 1974.
- KÜNZLER**, Hans: *Sübjektivismus und Objektivismus in der Lehre vom absolut untauglichen Versuch*, Zürich 1947.
- LANGER**, Winrich: *Das Sonderverbrechen. Eine dogmatische Untersuchung zum Allgemeinen Teil des Strafrechts*, Berlin, 1972.
- LEIPZIGER KOMMENTAR** zum Strafgesetzbuch, 8. Auflage, 1957; 10 Auflage, 1978 ve müteakip yıllar.
- LENCKNER**, Theodor: *Der rechtfertigende Notstand, zur Problematik der Notstandsregelung im Entwurfe eines Strafgesetzbuchs (E 1962)*, Tübingen, 1965.
- v.LISZT**, Franz: *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, 1. Auflage, Berlin/Leipzig, 1881; 14/15. Auflage, Berlin, 1905; 24. Auflage, Berlin, 1922.
- v.LISZT**, Franz/**SCHMIDT**, Eberhard: *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, 24. Auflage, Berlin/Leipzig, 1922; 25 Auflage, Berlin/Leipzig, 1927; 26. Auflage, Berlin/Leipzig, 1932.
- LOEWENHEIM**, Ulrich: *Error in Objecto ve Aberratio Ictus* (çeviren İÇEL, Kayıhan), in: İÜHFM 36(1971), SAYI 1-4, sh. 422 vd.
- MADEN**, Mehmet: *Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar*, Ankara 2012.
- MAHMUTOĞLU**, Fatih Selami: *Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi*, İstanbul, 1995.
- MAHMUTOĞLU**, Fatih Selami: *Türk Ceza Kanununun 463. Maddesi Hükümünün Taksirle İşlenen Suçlar Açısından Uygulanabilirliği Sorunu*, in: Adalet Yüksekokulu, 20. Yıl Armağanı, 2000.

- MAHMUTOĞLU**, Fatih Selami: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Hukuka Uygunluk Nedenleri, in: Hukuk ve Adalet Dergisi, yıl 2, sayı 5, Nisan 2005.
- MAHMUTOĞLU**, Fatih Selami: Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LXIII, yıl 2005, sayı 1-2, sh. 57 vd.
- MAIHOFER**, Werner: *Der Handlungsbegriff im Verbrechenssystem*, Tübingen, 1953.
- MALKOÇ**, İsmail: *Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu*, cilt I, Ankara, 2005.
- MALKOÇ**, İsmail/**GÜLER**, Mahmut: *Uygulamada Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu*, cilt II, Ankara, 1998.
- MAURACH**, Reinhart: *Kritik der Notstandslehre*, Berlin, 1935.
- MAURACH**, Reinhart: *Schuld und Verantwortung im Strafrecht*, Wolfenbüttel-Hannover, 1948.
- MAURACH**, Reinhart: *Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 4. Auflage, Karlsruhe, 1971.
- MAURACH**, Reinhart/**ZIPF**, Heinz: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband I*, 7. Auflage, Heidelberg, 1987.
- MAURACH**, Reinhart/**GÖSSEL**, Karl Heinz/**ZIPF**, Heinz: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2*, 7. Auflage, Heidelberg, 1989.
- MAYER**, Hellmuth: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, Stuttgart/Köln, 1953.
- MAYER**, Max Ernst: *Die schuldhaftige Handlung und ihre Arten im Strafrecht. Drei Begriffsbestimmungen*, Leipzig, 1901.
- MAYER**, Max Ernst: *Der Allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts*, 1. Auflage, Heidelberg, 1905; 2. Auflage, Heidelberg, 1923.
- MERAKLI**, Serkan: *Ceza Hukukunda Kusur*, Ankara, Ekim 2017.
- MERAN**, Necati: *Yeni Türk Ceza Kanununda Sahtecilik – Malvarlığı Bilişim Suçları ile Ekonomi ve Ticaret Alanında Suçlar*, Ankara, 2005.
- MERAN**, Necati: *Yeni Türk Ceza Kanununda Görevi Kötüye Kullanma Suçu*, in: Terazî Aylık Hukuk Dergisi, yıl 2, sayı 9, Mayıs 2007, sh. 102 vd.
- MERAN**, Necati: *Türk Ceza Kanununda Yasak Hatası*, in: Terazî Aylık Hukuk Dergisi, yıl 4., sayı 32, Nisan 2009, sh. 65 vd.
- MERAY**, Seha L.: *Devletler Hukukuna Giriş*, cilt 1, Ankara, 1959.
- MERKEL**, Adolf: *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*; Stuttgart, 1889.
- MEZGER**, Edmund: *Strafrecht. Ein Lehrbuch*, 1. Auflage, München/Leipzig, 1931 (unveränderte 2. Auflage, 1933, 3. Auflage, 1949).
- MEZGER**, Edmund: *Strafrecht I, Allgemeiner Teil, ein Studienbuch*, 9. Auflage, München/Berlin, 1960.
- MEZGER**, Edmund: *Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik. Eine ergänzende Betrachtung zum Lehrbuch des Strafrechts in seiner dritten Auflage (1949)*, Berlin/München, 1950.
- MEZGER**, Edmund: *Die subjektiven Unrechtselemente*, in: GS 89(1924), sh. 207 vd.
- MEZGER**, Edmund: *Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände*, in: Festschrift für Ludwig Traeger, 1926 (Repr. 1979), sh. 187 vd.

- MEZGER**, Edmund: *Rechtsirrtum und Rechtsblindheit*, in: Festschrift für E. Kohlrausch, 1944, sh. 180 vd.
- MEZGER**, Edmund: *Die Handlung im Strafrecht*, in: Festschrift für Theodor Rittler, Aalen, 1957, sh. 119 vd.
- MITTERMAIER**, Wolfgang: *Kritische Beiträge zur Lehre von der Strafrechtsschuld*, Giessen, 1909.
- MITTERMAIER**, Wolfgang: *Zur Frage des Schuldcharakters der Fahrlässigkeit*, in: ZStW 32(1911), sh. 415 vd.
- MOMMSEN**, Theodor: *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- MUMCU**, Ahmet: *İnsan Hakları, Kamu Özgürlükleri*, Ankara, 1992.
- NECATİGİL**, Zaim M.: *Suçluların İadesi ve Yabancıların Sınırdışı İşlemleri*, in: Kıbrıs Türk Federe Devletinin Milletlerarası Hukuka İlişkin Bazı Sorunları (Sempozyum, 6-7 Mayıs 1982). İstanbul, 1983, sh.113.
- NIESE**, Werner: *Finalitaet, Vorsatz und Fahrlaessigkeit*, Tübingen, 1951.
- NIESE**, Werner: *Der Irrtum über Rechtfertigungsgründe*, in: DRiZ 1953, sh. 20 vd.
- NOLL**, Peter: *Schuld und Prävention unter dem Gesichtspunkt der Rationalisierung des Strafrechts*, in: Beiträge zur gesamten Strafrechtswissenschaft, Festschrift für Hellmuth Mayer, Berlin, 1966, sh. 219 vd.
- NOWAKOWSKI**, Friedrich: *Das Ausmass der Schuld*, in: SchwZStr 65 (1950).
- NURSAL**, Necati/ATAÇ, Selcen: *Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi (Probation)*, Ankara, 2006.
- OEHLER**, Dietrich: *Das objektive Zweckmoment in der rechtswidrigen Handlung*, Berlin, 1959.
- OĞUZMAN**, Kemal/ÖZ, M. Turgut: *Borçlar Hukuku Dersleri*, cilt II, İstanbul, 1991.
- OKANDAN**, Recai Galip: *Umumî Âme Hukuku*, İstanbul 1976.
- OKAY**, Sadık: *Tekerrürün Mahiyeti Hakkında Başlıca Nazariyeler ve Tatbikata Tesirleri*, in: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt IX, sayı 12, sh. 331 vd.
- OZANSÜ**, Mehmet Cemil: *Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk*, Ankara 2007.
- ÖLMEZ**, Gökhan: *Suçun Tanımlanabilir ve Değerlendirilebilir Unsurları*, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, 2020.
- ÖNDER**, Ayhan: *Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler (Mukayeseli Hukukta ve Hukukumuzda)*, İstanbul, 1963.
- ÖNDER**, Ayhan: *Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Suç Genel Teorisi, Suçun Özel Belirliş Şekilleri*, cilt II, İstanbul, 1989.
- ÖNDER**, Ayhan: *Ceza Hukuku, Genel Hükümler*, cilt III, İstanbul, 1989.
- ÖNDER**, Ayhan: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, cilt I, İstanbul, 1991.
- ÖNDER**, Ayhan: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, cilt I-II, İstanbul 1992.
- ÖNDER**, Ayhan: *Ceza Hukuku Dersleri*, İstanbul, 1992.
- ÖNDER**, Ayhan: *Uluslararası Şiddet, Şiddet Eylemleri*, in: Milliyet, 28.12.1975.

- ÖNOK**, Rıfat Murat: *TCK'da Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Suretiyle İşlenen Suçlar*, in: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Ocak 2012, sh. 31 vd.
- ÖNOK**, Rıfat Murat: *Yapısal Suçlarda Failin Tespiti: Müşterek Suç Girişimi (Joint Criminal Enterprise) ve Örgütsel Hakimiyete Dayalı Dolaylı Faillik Doktrinleri*, Ankara, Mart 2019.
- ÖZANLI**, Aytekin: *Failin Ailevi ve Kişisel Durumunun Taksirli Suçlar Bakımından Değerlendirilmesi*, in: Terazi Aylık Hukuk Dergisi, yıl 4, sayı 32, Nisan 2009, sh. 57 vd.
- ÖZAY**, İl Han: *İdari Yaptırımlar*, İstanbul, 1985.
- ÖZAYDIN**, Özdem: *Notwehr und Notstand im deutsch-türkischen Rechtsvergleich*, Baden-Baden, Bern, 2013.
- ÖZBEK**, Veli Özer/**KANBUR**, Mehmet Nihat/**DOĞAN**, Koray/**BACAKSIZ**, Pınar/**TEPE**, İlker: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı, Suç Genel Teorisi, Yaptırım Teorisi*, 4. bası, Ankara, Eylül 2013.
- ÖZBEK**, Veli Özer/**DOĞAN**, Koray/**BACAKSIZ**, Pınar/**TEPE**, İlker: *Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı, Suç Genel Teorisi, Yaptırım Teorisi*, 7. bası, Ankara, 2016.
- ÖZBEK**, Veli Özer: *TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı (Açıklamalı-Gerekçeli-İçtihatlı)*, Cilt I, Genel Hükümler (Madde 1-75), 3. bası, Ankara 2006.
- ÖZBEK**, Veli Özer: *Ceza Muhakemesi Hukuku*, Ankara, 2006.
- ÖZBUDUN**, Ergun: *Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı: Hukuki Mahiyetleri*, in: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 59, Temmuz/Ağustos 2005, sh. 109 vd.
- ÖZDEMİR**, Kenan: *Ceza Hukukunda Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması*, in: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 59, Temmuz/Ağustos 2005, sh. 237 vd.
- ÖZEK**, Çetin: *Devlet Başkanına Karşı Suçlar*, İstanbul, 1970.
- ÖZEK**, Çetin: *Türk Basın Hukuku*, İstanbul 1978.
- ÖZEK**, Çetin: *Türk Ceza Kanununun 50 Yılında Devlete Karşı Suçlar*, in: Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Karşısında TCK'nın 50 Yılı Ve Geleceği, İstanbul, 1977, sh. 583 vd.
- ÖZEK**, Çetin: *1997 Türk Ceza Yasası Tasarısına İlişkin Düşünceler*, in: İÜHFM, Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'na Armağan Sayısı, cilt LVI, yıl 1998, sayı 1-4, sh. 21 vd.
- ÖZEK**, Çetin: *1997 Türk Ceza Yasa Tasarısı'na İlişkin Düşünceler*, Prof. Dr. Sahir Erman'a Armağan'dan ayrı bası, İstanbul, 1999.
- ÖZEK**, Çetin: *"Devletin Korunması", "Terörle Mücadele Yasası" ve "Bilgilenme Hakkı"*, in: Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet, Edip F. Çelik'e Armağan, İstanbul 1995, sh. 244 vd.
- ÖZEN**, Muharrem: *Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa*, Ankara 1995.
- ÖZEN**, Muharrem: *Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk*, Ankara 1998.
- ÖZENBAŞ**, Nazmiye: *Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Ceza Sorumluluğunun Esası*, Ankara, 2012.
- ÖZGEN**, Eralp: *Suçluların Geri Verilmesi*, Ankara, 1962.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Suç İştirakin Hukuki Esası ve Faillik*, İstanbul, 1996.

- ÖZGENÇ, İzzet: *Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar*, Ankara, 2002.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Uygulamalı Ceza Hukuku, Çözümlü Örnek Olaylar ve Karar Tahlilleri*, 2. bası, İstanbul Ekim 1998.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler)*, 3. bası, Ankara, 2006.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Terörle Mücadele Kanunu*, Ankara, 2006.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu*, Ankara, 2007.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Çek Kanunu*, 4. bası, Ankara, Ekim 2010.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Çek Kanunu*, 5. bası, Ankara, Şubat 2012.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Örgütleri*, 6. bası, Ankara, Nisan 2013.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Örgütleri*, 11. bası, Ankara, Şubat 2018.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Örgütleri*, 12. bası, Ankara, Ocak 2019.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Örgütleri*, 13. bası, Ankara, Ocak 2020.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Suç Örgütleri*, 14. bası, Ankara, Mart 2022.
- ÖZGENÇ, İzzet: *İhale Sürecinde İşlenen Suçlar*, 4. bası, Ankara, Mayıs 2013.
- ÖZGENÇ, İzzet: *İrtikâp, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları*, 2. bası, Ankara, Haziran 2013.
- ÖZGENÇ, İzzet/ŞAHİN, Cumhur: *Uygulamalı Ceza Hukuku*, 3. bası, Ankara, 2000.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Suçun Yapısında Kusur*, İstanbul, 1997 (yayınlanmamış Doçentlik Tezi).
- ÖZGENÇ, İzzet: *Türkiye'nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Türk İade Hukukunun Değerlendirilmesi*, (yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1984.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Müessir Bir Çevre Koruması ve Hukuk, Mer'i Hukukun Değerlendirilmesi*, in: Türk Devletleri Arasında 1. İlmî İşbirliği Konferansı (22-24 Haziran 1992-Lefkoşe, KKTC), Tebliğler, İstanbul, 1992, sh. 415 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet: *TCK'nın 5. Maddesine İlişkin Yargıtay'ın İki Farklı Kararının İncelenmesi, Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Etkisi*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LI, yıl 1985, sayı 1-4, sh. 627 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet: *"Kavga Suçu" (TCK., mad. 464) Üzerine Düşünceler*, in: Yargıtay Dergisi, cilt 19, sayı 4 (Ekim 1993), sh. 477 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Müşterek Faillik - Ceza Kanunu'nun 463. Maddesi Hükmünün ve Buna İlişkin Uygulamanın Değerlendirilmesi*, in: Yargıtay Dergisi, cilt 19, Ocak-Nisan 1993, sayı 1-2, sh. 86 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Kusur Yargısı ve Yaş Küçüklüğü*, in: Facultatis Decima Anniversaria (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu), İstanbul, 1993, sh. 251 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Emniyet Görevlilerinin Silah Kullanma Yetkisi Üzerine Düşünceler*, İstanbul Barosu Dergisi, cilt 68, sayı 1-2-3, (Ocak, Şubat, Mart 1994), sh. 90 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Failliğin Üçüncü Bir Görünüş Şekli Olarak Müşterek Faillik*, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 4, 1994, sayı 1-2, sh. 159 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Kamu Görevi, Yükümlülük Suçları, Yükümlülük Suçlarına İştirak (KARAR İNCELEMESİ)*, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Yıl 1994, sayı 1-2, sh. 329 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet: *Tüzeltişinin Sorumluluk Ehliyeti - Anayasa Mahkemesi'nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler*, in: Reha POROY'a Armağan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını), İstanbul 1995, sh. 319 vd.

- ÖZGENÇ**, İzzet: *Suç Zanlısı Kişinin Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü ve Bunun Hukuki Sonuçları*, in: Hukuk Araştırmaları, cilt 9, yıl 1995, sayı 1-3, sh. 134.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *İnsan Haklarının Felsefi Temeli*, in: İnsan Hakları, İstanbul, 1995, sh. 41 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Davranış Normları Teorisi, Haksızlık ve Müeyyide İlişkisi*, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 5, yıl 1996, sayı 1-2, sh. 430 vd.; ayrıca, özet olarak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Sabahaddin Zaim'e Armağan, yıl 1994/B-3, cilt 1-4, İstanbul 1996, sh. 409 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Askerî Hiyerarşide Emirlerin Bağlayıcılığı ve Bunun Hukuki Sonuçları*, in: İnsan Kaynakları Yönetimi Sempozyumu 20-21 Haziran 1996 [TEBLİĞLER], (Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yayını), Konya 1996, sh. 105 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Suç Teşekkülü, Düşünceyi Açıklama ve Örgütlenme Hürriyeti*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Türkan Rado'ya Armağan Sayısı, cilt LV, yıl 1997, sayı 3, sh. 51 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Kast-Taksir Kombinasyonları*, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Süleyman Arslan Armağanı, cilt 6, yıl 1998, sayı 1-2, sh. 345 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *İnsan Haklarının Özüne Dönüş*, in: Yeni Türkiye, Mayıs-Haziran 1998, yıl 4, sayı 21, sh. 606 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Düşünceyi Açıklama Hürriyeti ve Ceza Hukuku*, in: 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu, Diyarbakır, 22-23 Ekim 1998, sh. 180 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi*, in: Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan 1999, sh. 70 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi*, in: Kamu Hukuku Arşivi, yıl 2, sayı 1, Şubat 1999, sh. 5 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu*, in: Kamu Hukuku Arşivi, yıl 3, sayı 2-3, Haziran-Ekim 2000, sh. 90 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Bir Ceza İnfaz Rejimi Olarak Erteleme*, in: Anayasa Yargısı, cilt 18, Ankara 2001.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *"Non bis in idem" Kuralının Milletlerarası Değeri ve TCK'nın 10/A Maddesi Hükümüne İlişkin Değerlendirme*, in: Yargıtay Dergisi, Temmuz 2002.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Marka Hakkına Tecavüz ve Cezaî Sorumluluk*, in: Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp'e Armağan, cilt III, İstanbul, 2003, sh. 831 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Banka Yolsuzlukları ve Zamanaşımı Sorunu*, in: Türk Hukuk, Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 71, Ocak 2003, sh. 4 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Bilinçli Taksir*, in: Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı (Galatasaray Üniversitesi yayını), İstanbul, 2004, sh. 697 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Suç ve Yaptırım Teorisine İlişkin Yeni Gelişmeler Işığında Türk Ceza Kanunu Tasarısı*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, Birinci Kitap, Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu, Panel, Ankara, 21-22 Mayıs 2004, Türkiye Barolar Birliği yayını, sh. 55 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Yeni Türk Ceza Kanunundaki Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar*, in: Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, Adalet Bakanlığı/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 30 Nisan-1 Mayıs 2005, Ankara, sh. 73 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Hekimlik Mesleğinin İcrası ve Ceza Sorumluluğu*, in: Ankem Dergisi, yıl 2006, cilt 20, Ek 2, sh. 10 vd.

- ÖZGENÇ**, İzzet: *Hekimin Tedavi Nedeniyle Ceza Sorumluluğuna İlişkin Röportaj*, in: Sağlıkta Nabız Dergisi, yıl 2006, sayı 18, sh. 4 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler*, in: SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos 2007, sayı 3, sh. 76 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Ceza Sorumluluğu: Cezai Sorumluluk*, in: SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Mart-Nisan-Mayıs 2011, sayı 18, sh. 88 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Değerlendirme ve Sonuç*, in: Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu, Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi yayını; Editörler: Cumhur Şahin, İzzet Özgenç ve İlhan Üzülmüş, 2. bası, Ankara, Ocak 2012 sh. 91 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: “*Şiddet Uygulayan Kişinin Zorlama Hapsine Tabi Tutulması*”, in: Yoncalı Platformu Sempozyum Günleri, Kütahya, Türkiye’de Aile İçi Şiddetle Mücadele Hukuk Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuku Dergisi, yıl 2012, cilt 8, sayı 97-98, sh. 59 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: “*Fuhuş ve Hukuk, Anayasa Mahkemesinin 18.10.2017 tarihli ve 2014/19152 numaralı Bireysel Başvuru Kararının Değerlendirilmesi*”, in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan (Editörler, F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoğlu, A. Sözüer, F. Turhan), Ankara, Mayıs 2018, sh. 483 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *İnsan Öldürme İle İlgili Kur’an Hükümlerinin Günümüz Ceza Hukuku Düşüncesine Aktarılması*, in: Dr.Dr.h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Editörler: F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoğlu, A. Sözüer, F. Turhan, Ankara, Mayıs 2018, sh. 503 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: “*Die aktuellen Probleme in der Praxis des Türkischen Strafvollstreckungsrechts*”, in: Dr.Dr.h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Editörler: F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Nuhoğlu, A. Sözüer, F. Turhan, Ankara, Mayıs 2018, sh. 1177 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Cinsel Suçlar Bağlamında, Kur’an Hükümleri Üzerine Bir Değerlendirme*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXII, Temmuz 2018, sayı 3, sh. 57 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Davranış Normları Teorisi, Hukuk ve Ahlak İlişkisi*, in: TÜBA Günce, sayı 59, Ocak 2019, sh. 30 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Yaptırım Teorisi ve İnfaz Siyaseti*, in: TÜBA Günce, sayı 60, Mayıs 2019, sh. 30 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Cinsel Suçlar, Türk Ceza Kanununun Cinsel Suçlara İlişkin Düzenlemelerinin Dayandığı Felsefi Temel, Cinsel Suçlara İlişkin Kanun Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlar*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXIV, sayı 1, Ocak 2020, sh. 257 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bakımından İlgilinin Rızasının Ceza Hukuku Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXIV, sayı 2, Nisan 2020, sh. 251 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet: *COVID-19 Salgınının Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku ve Milletlerarası Hukuk Alanında Sebebiyet Verdiği veya Verebileceği Sorunlar ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri*, in: TÜBA Covid-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu, Covid-19 Salgını Dolayısıyla Ulusal veya Uluslararası Alanda Ortaya Çıkan/Çıkabilecek Hukuki Sorunların Çözümüne Yönelik Öneriler Raporu, Türkiye Bilimler Akademisi yayını, Ankara, Temmuz 2020, sh. 11 vd.
- ÖZGENÇ**, İzzet/**BAYRAKTARLI**, İhsan Yılmaz: *İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XXIII, Ocak 2019, sayı 1, sh. 129 vd.

- ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem:** *Basın Hürriyeti Kavramı, Basın Yoluyla İşlenen Suçlarda Sorumluluk Rejimi ile Cevap ve Düzeltme Hakkı Üzerine Düşünceler*, in: Yeni Türkiye, Eylül-Ekim 1996, yıl 2, sayı 11, sh. 272 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet/ŞAHİN, Cumhur:** *Kamu Görevi, Muafiyet ve Dokunulmazlık Kavramları Üzerine Düşünceler*, in: Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1997, yıl 3, sayı 14, sh. 911 vd.
- ÖZGENÇ, İzzet/ŞAHİN, Cumhur:** *İnfaz Hukuku*, 5. bası, Ankara, Ekim 2022.
- ÖZKAN, Halid:** *Ceza Hukukunda Azmettirme*, Ankara 2013.
- ÖZTAN, Bilge:** *Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk*, Ankara, 1970.
- ÖZTÜRK, Bahri:** *Ceza Muhakemesi Hukukunda Koğuşurma Mecburiyeti (Hazırlık Soruşturması)*, Ankara, 1991.
- ÖZTÜRK, Bahri:** *Ceza ve Emniyet Tedbirleri Hukuku*, İzmir, 1992.
- ÖZTÜRK, Bahri:** *Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku*, 3. bası, Ankara, 1994.
- ÖZTÜRK, Bahri:** *Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Çare Olarak Seyirden Yasaklanma*, in: Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu, Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi yayını; Editörler: Cumhur Şahin, İzzet Özgenç ve İlhan Üzülmöz, 2. bası, Ankara, Ocak 2012, sh. 33 vd.
- ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan:** *Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Ceza Hukukuna Egemen Olan İlkeler, Ceza Kanunlarının Uygulama Alanı, Suç Genel Teorisi, Suçun Özel Görünüş Biçimleri (Teşebbüs, İctima, İştirak), Ceza ve Güvenlik Tedbirleri, Ceza İlişkisini Ortadan Kaldıran Nedenler*, 12. bası, Ankara, 2012.
- ÖZTÜRK, Bahri:** *Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Barosu Tarafından Düzenlenen TCK Tasarısı Çalışma Grubu Toplantı Notları*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Ankara, Eylül 2004, Türkiye Barolar Birliği yayını, sh. 319 vd.
- PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer:** *Türk Ceza Kanunu Yorumu*, cilt 2, Ankara, Şubat 2007.
- PETERS, Karl:** *Strafprozess, Ein Lehrbuch*, Heidelberg, 1985.
- PUPPE, Ingeborg:** *Vorsatz und Zurechnung*, Heidelberg, 1992.
- RADBRUCH, Gustav:** *Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem*, Berlin 1904.
- RADBRUCH, Gustav:** *Über den Schuldbegriff*, in: ZStW 24 (1904), sh. 333 vd.
- RADBRUCH, Gustav:** *Zur Systematik der Verbrechenslehre*, in: Festgabe für Reihard vo Frank, Band I, Tübingen 1930, sh. 158 vd.
- RAESTAD, Arnold:** *Melce Hakkı* (çeviren Tarık E. Yenisey), in: Ad. Cer., yıl 1938, sh. 1784.
- RITTNER, Theodor:** *Lehrbuch des österreichischen Strafrecht*, 2. Aufl. Wien 1954
- ROSENAU, Henning:** *Embryonenforschungund therapeutisches Klonen nach der Biomedizin-Konventions des Europarates*, in: Kamu Hukuku Arşivi (KHUKA), Kasım 2005, yıl 8, sh. 131 vd. Tercüme: **HAKERİ, Hakan:** *Avrupa Konseyi Biyo-Tıp Sözleşmesine Göre Embriyon Araştırmaları ve Tedavi Amaçlı Klonlama*, in: KHUKA, Kasım 2005, sh. 137 vd.
- RÖSSNER, Dieter:** *Autonomie und Zwang im System der Strafrechtsfolgen*, in: Festschrift für Jürgen Baumann, Bielefeld, 1992, sh. 269 vd.
- ROXIN, Claus:** *Offene tatbestände und Rechtspflichtmerkmale*, 2. Auflage, Berlin, 1970.

- ROXIN**, Claus: *Kriminalpolitik und Strafrechtssystem*, 2. Auflage, Berlin, 1973.
- ROXIN**, Claus: *Täterschaft und Tatherrschaft*, 4. Auflage, Berlin/ New York, 1984.
- ROXIN**, Claus: *Strafverfahrensrecht*, 20. Auflage, München, 1987.
- ROXIN**, Claus: *Strafrecht - Allgemeiner Teil, Band: I, Grundlagen - Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 1. Auflage, München 1992, 2. Auflage, München 1994.
- ROXIN**, Claus: Zur Kritik der finalen Handlungslehre: ZStW 74(1962), sh. 515 vd.
- ROXIN**, Claus: *Die Behandlung des Irrtums im E.1962*, in: ZStW 76(1964), sh. 582 vd.
- ROXIN**, Claus: Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, in: JuS 1966, sh. 377 vd.
- ROXIN**, Claus: *Kriminalpolitische Überlegungen zum Schuldprinzip*, in: MschrKrim 56[1973], sh. 316 vd.
- ROXIN**, Claus: “Schuld” und “Verantwortlichkeit” als strafrechtliche Systemkategorien, in: Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft, Festschrift für Heinrich Henkel, Berlin/New York, 1974, sh. 171 vd.
- ROXIN**, Claus: *Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht*, in: Festschrift für Paul Bockelmann, München, 1979, sh. 279 vd.
- ROXIN**, Claus: *Was bleibt von der Schuld im Strafrecht übrig?*, in: SchwZStr 104[1987], sh. 641 vd.
- ROXIN**, Claus: *Das Schuldprinzip im Wandel*, in: *Strafgerechtigkeit*, in: Festschrift für Arthur Kaufmann, Heidelberg, 1993, sh. 519 vd.
- ROXIN**, Claus: *Yasağa İlişkin Yanılma* (Tercüme: Osman İsfen), in: Suç Politikası, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Serisi, no. 5, Ankara, 2005.
- RUDOLPHI**, Hans-Joachim: *Der Zweck staatlichen Strafrechts und die strafrechtlichen Zurechnungsformen*, in: Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, (Hrsg.: Bernd Schünemann), 1984, sh. 69 vd.
- SAVAŞ**, Vural/**MOLLAMAHMUTOĞLU**, Sadık: *Türk Ceza Kanununun Yorumu*, cilt I, II, III, IV, Ankara, Ocak 1995.
- SCHAFFSTEIN**, Friedrich: *Die allgemeine Lehren vom Verbrechen*, Aalen 1973.
- SCHMIDHÄUSER**, Eberhard: *Vom Sinn der Strafe*, 2. Auflage, Göttingen, 1971.
- SCHMIDHÄUSER**, Eberhard: *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch*, 2. Auflage, Tübingen, 1975.
- SCHÖNKE**, Adolf/**SCHRÖDER**, Horst: *Strafgesetzbuch. Kommentar*, 17. Auflage, München, 1974; 23. Auflage, München, 1988.
- SCHROEDER**, F.-C.: *Probleme der Legislatorischen Feststellung der Fahrlässigkeit* (Taksirin Kanunen Tanımlanmasına İlişkin Problemler [Tercüme: İ. Özgenç]), in: Türk Ceza Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler (Diskussionsbeiträge zum Entwurf des Türkischen Strafgesetzbuchs), Konya 1998, sh. 255 vd.
- SCHÜNEMANN**, Bernd: *Einführung in das strafrechtliche Systemdenken*, in: Grundfragen des modernen Strafrechtssystems (Hrsg.: Bernd Schünemann), Berlin, 1984, sh. 1 vd.
- SCHÜNEMANN**, Bernd: *Die Funktion des Schuldprinzips im Präventionsstrafrecht*, in: Grundfragen des modernen Strafrechtssystems (Hrsg.: Bernd Schünemann), Berlin, 1984, sh. 153 vd.

- SCHÜNNEMANN**, Bernd: *Strafrechtssystem und Kriminalpolitik*, in: Festschrift für Rudolf Schmitt, Tübingen, 1992, sh. 117 vd.
- SIEVERTS**, Rudolf: *Beitraege zur Lehre von den subjektiven Unrechtselementen im Strafrecht*, Hamburg, 1934.
- SONGAR**, Ayhan: *Psikiyatri Psikobiyoloji ve Ruh Hastalıkları*, 4. bası, İstanbul 1980.
- SOYASLAN**, Doğan: *Teşebbüs Suçu*, Ankara, 1994.
- SOYASLAN**, Doğan: *Kriminoloji (Suç ve Ceza) Dersleri*, Ankara, 1996.
- SOYASLAN**, Doğan: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, Ankara, 1998.
- SOYASLAN**, Doğan: *Ceza Hukuku Genel Hükümler*, 4. bası, Ankara, 2012.
- SOYASLAN**, Doğan: *Ceza Hukuku Özel Hükümler*, 3. bası, Ankara, 1999.
- SOYASLAN**, Doğan: *Şartlı Tahliye*, in: Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989, sh. 522.
- SOYASLAN**, Doğan: *Ceza Hukuku İle Diğer Hukuk Dalları ve Özellikle Anayasa Hukuku İlişkisi*, in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Jale G. Akipek'e Armağan, Konya, 1991, sh. 111 vd.
- SOYASLAN**, Doğan: Hukuk Merceği, Ankara Barosu Yayını, yıl 2006, sayı 6, sh. 575
- SÖZÜER**, Adem: *Suçta Teşebbüs*, İstanbul, 1994.
- SÖZÜER**, Adem: *Einführung in die Gesamtreform des Türkischen Strafrechts*, İstanbul, 2006.
- SÖZÜER**, Adem: *Tehdit Suçu*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LIV, yıl 1991-1994, sayı 1-4, sh. 125 vd.
- SÖZÜER**, Adem: *Hukuki Hata*, in: Yargıtay Dergisi, cilt 21, Ekim 1995, sayı 4, sh. 466 vd.
- SPENDEL**, Günter: *Zur neue Begründung der objektiven Versuchstheorie*, in: Festschrift für Ulrich Stock 1964.
- STRATENWERTH**, Günter: *Strafrecht, Allgemeiner Teil I. Die Straftat*, 3. Auflage, Köln/Berlin/Bonn, 1981.
- STRATENWERTH**, Günter: *Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips*, Heidelberg/Karlsruhe, 1977.
- STRENG**, Franz: *Schuld, Vergeltung, Generalprävention*, in: ZStW 92(1980), sh. 637 vd.
- SYSTEMATISCHER KOMMENTAR** zum Strafgesetzbuch (**RUDOLPHI**, Hans Joachim/**HORN**, Eckhard/**SAMSON**, Erich/**GÜNTHER**, Hans-Ludwig), 6. Auflage, Berlin, März, 1995.
- ŞAHİN**, Cumhur: *Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması*, Ankara, 1994.
- ŞAHİN**, Cumhur: *Ceza Muhakemesi Hukuku I*, 4. bası, Ankara, Eylül 2013.
- ŞAHİN**, Cumhur/**ÖZGENÇ**, İzzet/**KILIÇ**, Ali Şahin: “*Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması*”, in: Prof. Dr. Rıza Ayhan’a Armağan, cilt II, Ankara, Haziran 2022, sh. 2301 vd.
- ŞEN**, Ersan: *1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku*, İstanbul, 1998.
- ŞENSOY**, Naci: *Cezaî Mesuliyeti Tamamen veya Kısmen Kaldıran Akli Malûliyet*, İstanbul, 1950.
- ŞİRİN**, Osman: *Silah Kullanan Kolluk Görevlileri Hakkında Verilen Yargıtay Kararları*, in: Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, İstanbul 2005, sh. 83 vd.
- TANER**, Fahri Gökçen: *Ceza Hukukunda Zamanaşımı*, Ankara, 2008.

- TANER**, M. Tahir: *Ceza Hukuku Umumi Kısım*, 3. Bası, İstanbul, 1953.
- TAŞKIN**, Ahmet. *Organ ve Doku Nakillerinde Hekimin Cezai Sorumluluğu*, Ankara 1997.
- TEKİNAY**, Selâhattin Sulhi: *Borçlar Hukuku*, cilt I, 5. bası, İstanbul, 1985.
- TEZCAN**, Durmuş: *Territorialite Et Conflits De Juridictions En Droit Penal International*, Ankara, 1983.
- TEZCAN**, Durmuş: *Yurt Dışında İşlenen Suçlarda Türk Hukuku Bakımından Yabancı ceza Kanununun Değeri Sorunu*, in: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt XXXIX, yıl 1984, sayı 1-4, sh. 111 vd.
- TEZCAN**, Durmuş/**ERDEM**, Mustafa Ruhan: *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin TCK Tasarısı Hakkında Raporu*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2004, sh. 327 vd.
- TEZCAN**, Durmuş/**ERDEM**, Mustafa Ruhan/**SANCAKDAR**, Oğuz: *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu*, 2. bası, Ankara, 2004.
- TEZCAN**, Durmuş/**ERDEM**, Mustafa Ruhan/**ÖNOK**, Murat: *Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku*, 18. bası, Ankara, Eylül 2020
- TEZCAN**, Durmuş/**ERDEM**, Mustafa Ruhan/**ÖNOK**, R. Murat: *Uluslararası Ceza Hukuku*, Ankara, 2009.
- TOROSLU**, Nevzat: *Ceza Hukukunda Zaruret Hali*, Ankara, 1968.
- TOROSLU**, Nevzat: *Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu*, Ankara, 1970.
- TOROSLU**, Nevzat: *Nasıl Bir Ceza Kanunu*, Ankara, 1987.
- TOROSLU**, Nevzat: *Ceza Hukuku*, 2. bası, Ankara, Mart 1991.
- TOROSLU**, Nevzat: *Ceza Hukuku*, 4. bası, Ankara, Ocak 1998.
- TOROSLU**, Nevzat: *Ceza Hukuku, Genel Kısım*, 8. bası, Ankara, Ekim 2005.
- TOROSLU**, Nevzat: *Ceza Hukukunda Okullar*, in: Prof. Dr. Nurullah Kunter'e Armağan, İstanbul 1998, sh. 367 vd.
- TOROSLU** Nevzat/**ERSOY**, Yüksel: *Kanunlaşmaması Gereken Bir Tasarı*, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2004, sh. 1 vd.
- TOSUN**, Öztekin: *Suç Hukuku El Kitabı*, 2. bası, İstanbul 1982.
- TOSUN**, Öztekin: *Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri*, cilt I, Genel Kısım, 4. bası, İstanbul, 1984.
- TOSUN**, Öztekin: *Yürütme Organlarının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması*, in: İÜHFM, cilt XXVIII, sayı 2, İstanbul, 1962, sh. 351.
- TULAY**, Muhammet Emre: *Suç Ortaklarının Cezai Sorumluluğu Üzerinde Kamu Görevlisi Sıfatının Hukuki Etkisi*, in: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 70, sayı 4, yıl 2021, sh. 1223 vd.
- TULAY**, Muhammet Emre: *Türk Ceza Hukukunda İntihara Yönlendirme Suçu*, in: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt 26, sayı 2, Aralık 2020, sh. 814 vd.
- TURHAN**, Faruk: *Yeni Türk Ceza Kanunu'na Göre Cezaların Ertelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar*, in: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt X, sayı 3-4, yıl 2006, sh. 27 vd.
- TUTANAKLARLA TÜRK CEZA KANUNU**, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Ankara, Şubat 2005.

- TÜMERKAN**, Somay: *Klasik, Pozitivist Okullarda ve Toplumsal Savunma Hareketinde Ceza Sorumluluğunun Esası*, in: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt: XLVIII-XLIX, yıl 1982-1983, sayı 1-4, sh. 51 vd.
- TÜRK CEZA KANUNU ÖNTASARISI**. Komisyonca Hazırlanan Metin, Ankara, 1987.
- TÜRK CEZA KANUNU ÖNTASARISININ GEREKÇESİ**, Ankara, 1987.
- TÜRK CEZA KANUNU ÖNTASARISI**. İkinci Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirme Sonunda Hazırlanan Metin, Ankara-Mart, 1989.
- UCHIYAMA**, Minoru: *Das Wertwidrige in der Ethik Max Schelers*, Bonn, 1966.
- ULUTAŞ**, Ahmet: *Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Işığında Suçluların Geri Verilmesi*, Ankara, Ekim 2012.
- ULUTAŞ**, Ahmet/**ATABEY**, Ömer Serdar: *Ceza alanında Uluslararası Adli İşbirliği Hukuku*, Ankara, Nisan 2011.
- UYGUN**, Mehmet/**SAVAŞ**, Vural/**MOLLAMAHMUTOĞLU**, Sadık: *Ceza Genel Kurulu Kararları*, Ankara, 1987.
- ÜNVER**, Yener: *Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk*, İstanbul, 1998.
- ÜNAL**, Osman Gazi: *Türk Ceza Hukukunda Tehlike Suçları*, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, 2020.
- ÜNVER**, Yener: *Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer*, Ankara, 2003.
- ÜNVER**, Yener: *Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi* (yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1989.
- ÜNVER**, Yener: *Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk*, in: Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, 1998, sh. 109 vd.
- ÜNVER**, Yener: *Türkiye’de Ceza Hukuku Alanında Yapılan Yakın Tarihli Düzenlemelerde Tıp Hukukuna İlişkin Birkaç Sorun*, in: Uluslararası katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyum Kitabı, İstanbul, 2005, sh. 105 vd.
- ÜNVER**, Yener: *YTCK’da Kusurluluk*, in: Ceza Hukuku Dergisi, yıl 1, sayı 1, Ekim 2006, sh. 37 vd.
- ÜNVER**, Yener: *Hekim ve Hasta Haklarının Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Konumlandırılması*, in: Ceza Hukuku Dergisi (CHD), yıl 2, sayı 1, Nisan 2007, sh. 199 vd.
- ÜZÜLMEZ**, İlhan: *Türk Hukukunda Tekerrür*, Ankara, 2003.
- ÜZÜLMEZ**, İlhan: *Ceza Sorumluluğunun Esası ve Cezalandırmanın Amacına Dair Düşünce Hareketleri*, *Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi*, in: Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: V, yıl 2001, sayı 1-4, sh. 259 vd.
- ÜZÜLMEZ**, İlhan: *Yeni Türk Ceza Kanunu’nda İşkence ve Eziyet Suçu*, in: Hukuk ve Adalet Dergisi, yıl 2, sayı 5, Nisan 2005.
- ÜZÜLMEZ**, İlhan: *Yeni Ceza Kanunu’nun Sisteminde Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi*, in: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt X, sayı 3-4, yıl 2006, sh. 203 vd.
- ÜZÜLMEZ**, İlhan/**AKKAŞ**, Ahmet Hulusi: *Suçun Yapısında Objektif Cezalandırılabilme Şartları*, in: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EÜHFD), cilt II, sayı 1-2, yıl 2007, sh. 71 vd.

- WALDER**, Hans: *Die Vernehmung des Beschuldigten*, Hamburg, 1965.
- v.WEBER**, Hellmuth: *Zum Aufbau des Strafrechtssystems*, Jena, 1935.
- WEGNER**, Arthur: *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Göttingen 1954.
- WELZEL**, Hans: *Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht*, Mannheim/Berlin/ Leipzig, 1935.
- WELZEL**, Hans: *Um die Finale Handlungslehre*, 1949.
- WELZEL**, Hans: *Aktuelle Strafrechtsprobleme im Rahmen der finalen Handlungslehre*, Karlsruhe, 1953.
- WELZEL**, Hans: *Das neue Bild des Strafrechts*, 4. Auflage, Göttingen, 1961.
- WELZEL**, Hans: *Das deutsche Strafrecht*, 11. Auflage, Berlin, 1969.
- WELZEL**, Hans: *Kausalität und Handlung*, in: ZStW 51(1931), sh. 703 vd.; ayrıca Welzel, Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975, sh. 7 vd.
- WELZEL**, Hans: *Über Wertungen im Strafrecht*, in: GS 103(1933), sh. 340 vd.; ayrıca Welzel, Abhandlungen, sh. 23 vd.
- WELZEL**, Hans: *Studien zum System des Strafrechts*, in: ZStW 58(1939), sh. 491 vd.; ayrıca Welzel, Abhandlungen, sh. 29 vd.
- WELZEL**, Hans: *Naturrecht und Rechtspositivismus*, in: Festschrift für H. Niedermeyer, 1953, sh. 279 vd.; ayrıca Welzel, Abhandlungen, sh. 274 vd.
- WELZEL**, Hans: *Die Regelung von Vorsatz und Irrtum im Strafrecht als legislatorisches Problem*, in ZStW 67(1955), sh. 208 vd.
- WELZEL**, Hans: *Die deutsche strafrechtliche Dogmatik der letzten 100 Jahre und die finale Handlungslehre*, in: JuS, 1966, sh. 421 vd.
- WESSELS**, Johannes: *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 19. Auflage, Heidelberg, 1989.
- YAKIT**, İsmail: *Semantik Analizler Işığında “Reyb” ve “Yakîn” Kavramları*, in Kur’an ve Dil Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2001, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını, sh. 51 vd.
- YARSUVAT**, Duygun: *Yürütme Organının Koyduğu Kaidelerle Suç İhdası ve 1961 Anayasası*, in: İÜHFM, cilt XXIX, sayı 3, İstanbul, 1963.
- YARSUVAT** Duygun/**BAYRAKTAR**, Köksal ile bir kısım öğretim elemanları tarafından hazırlanan “*Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinin TCK Tasarısı Hakkındaki Görüşleri*”, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2004, sh. 285 vd.
- YAŞAR**, Osman: *Uygulamada Türk Ceza Yasası, Genel Hükümler*, Ankara, 2000.
- YAŞAR**, Osman/**GÖKCAN**, Hasan Tahsin/**ARTUÇ**, Mustafa: *Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu*, cilt VI, Ankara 2010.
- YENİDÜNYA**, Ahmet Caner: *Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme*, İstanbul, Eylül 2002.
- YENİSEY**, Feridun: *Milletlerarası Ceza Hukuku*, İstanbul 1988.
- YENİSEY**, Feridun: *Duruşma ve Kanun Yolları*, İstanbul, 1988.

- YENİSEY**, Feridun: *Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma*, in: Ad. Der. 1981 sayı 4, sh. 590.
- YENİSEY**, Feridun: *Milletlerarası Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler*, in: Ceza Hukuku Günleri, İstanbul 1998, sh. 47.
- YENİSEY**, Feridun: *Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi: Mukayeseli Hukuk, AİHM Kararları*, in: Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, İstanbul 2005, sh. 95 vd.
- YILDIZ**, Ali Kemal: *Dolayısıyla Faillik*, in: Ceza Hukuku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler (26-27 Mart 1997), İstanbul 1998.
- YILMAZ**, Zekeriya: *Gerekçe ve Tutanaklarla Yeni Türk Ceza Kanunu*, Ankara, 2004.
- YILMAZ**, Zekeriya: *Teori ve Uygulamada Müsadere*, Ankara 2003.
- YURTCAN**, Erdener: *Ceza Yargılamasında Kesin Hüküm*, 2. bası, İstanbul, 1987.
- YURTCAN**, Erdener: *Ceza Yargılaması Hukuku*, 5. bası, İstanbul 1996.
- YURTCAN**, Erdener: *Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Şerhi ve İlgili Mevzuat*, cilt III, İstanbul, 1988.
- YURTCAN**, Erdener: *CMUK Şerhi*, 3. bası, İstanbul, Mart 2000.
- YURTLU**, Fatih: *İhmalî Suçlar*, 31.8.2021 tarihi itibarıyla yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kasım 2020.
- YURTLU**, Fatih: *Suç Teorisi Bakımından İhmalî Suçların Yapısı*, in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 25, sayı 3, Temmuz 2021, sh. 581 vd.
- YURTLU**, Fatih: *İhmalî Suçlar*, henüz yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kasım 2020.
- YÜCE**, Turhan Tûfan: *Ceza Hukuku Dersleri, cilt I, Giriş: Genel Bilgiler. Ceza Hukukunun Yürürlüğü, Suç Teorisi*, Manisa, 1982.
- YÜCE**, Turhan Tûfan: *Ceza Hukukunun Temel Kavramları*, Ankara, 1985.
- YÜCE**, Turhan Tûfan: *Ümanizma Görüşü ile Hukuki Bilmeme ve Yanılma*, in: Birinci Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğler, Ankara, 1972'den ayrı bası.
- YÜCEL**, Hasan-Âli: *Allah Bir*, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1961.
- YÜCEL**, Mustafa Tören: *Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi, Suç ve Ceza*, Ankara, 1999.
- ZAFER**, Hamide: *Ceza Hukuku Genel Hükümler, TCK m. 1-75, Ders Kitabı*, 2. Bası, İstanbul, 2011.
- ZIEGERT**, Ulrich: *Vorsatz, Schuld und Vorverschulden*, Berlin, 1987.
- ZIELINSKI**, Diethart: *Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff*, Berlin, 1973.

Dizin

A

Actiones Liberae In Causa, 487
Adli Bilimler, 61
Adli Kontrol, 1083, 1084
Adli Para Cezası, 66, 67, 95, 96, 119, 130, 150, 325, 376, 479, 674, 827, 829, 830, 831, 833, 838, 844, 845, 852, 853, 855, 858, 859, 861, 862, 873, 896, 897, 911, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 963, 991, 1003, 1023, 1024, 1025, 1026, 1029, 1030, 1035, 1041, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1083, 1084, 1104, 1109, 1111, 1125, 1132, 1153, 1189
Adli Sicil, 67, 116, 119, 811, 907, 914, 987, 988, 989, 994, 995, 1152
Adli Sicil Arşiv Kaydı, 987
Adli Sicil Kaydı, 116, 811, 1153
Adli Tıp, 61, 198, 200, 202
Af, 95, 991, 992, 1095, 1109, 1110, 1188
Affekt Hareketler, 184
Ağır Hapis Cezası, 197, 257, 334, 812, 885, 894, 990
Ağır Para Cezası, 95, 116, 124, 151, 152, 242, 275, 557, 829, 895, 896, 911, 913, 916, 991
Ağır Tahrik, 533, 535
Ağırlaştırılmış Müebbet Ağır Hapis Cezası, 885
Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası, 101, 198, 301, 476, 536, 633, 638, 647, 809, 811, 879, 882, 885, 886, 1028, 1051, 1073, 1089, 1190
Ağırlatıcı Nedenler, 652
Ağırlatıcı Sebepler, 230, 652, 653
Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbiri, 484, 485, 971, 1021, 1022
Akıl Hastalığı, 81, 114, 389, 390, 461, 471, 476, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 491, 539, 637, 780, 798, 1021, 1069, 1070, 1071
Akim Kalmış Azmettirme, 639

Alenilik, 350

Aleniyet, 34, 231

Algılama Yeteneği, 92, 376, 462, 463, 465, 469, 470, 475, 480, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 550, 553, 1071

Amaç, 36, 37, 38, 85, 94, 104, 149, 165, 166, 233, 303, 304, 322, 323, 324, 328, 345, 349, 362, 485, 491, 547, 564, 620, 655, 676, 677, 704, 706, 773, 791, 793, 800, 812, 853, 855, 857, 867, 874, 911, 968, 969, 987, 995, 1040, 1041, 1058, 1092, 1159, 1192, 1193, 1197, 1222

Amaç Suç, 104, 677

Ani Suç, 192

Araç Suç, 677

Arama, 64, 336, 507, 515, 570

Askeri Suç, 111, 1203, 1214, 1215

Asli Ceza, 67, 94, 115

Aydınlatılmış Onam, 385, 392, 393

Aynı Neviden Fikri İctima, 712

Azmettirme, 93, 117, 603, 604, 611, 625, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 649, 652, 1069

Azmettirmeye Azmettirme, 641

B

Bağlı Hareketli Suç, 186, 188

Bağlılık Kuralı, 215, 603, 607, 636, 637, 640, 646, 649, 650, 651, 652, 673

Bağlılık Kuralının Çifte Fonksiyonu, 650, 651

Basın ve Yayın Yoluyla, 319, 1202

Belirlilik İlkesi, 85, 106, 120, 121, 131, 132, 133

Beraat, 65, 152, 156, 282, 319, 336, 338, 362, 476, 477, 501, 508, 522, 678, 771, 773, 774, 796, 797, 832, 1082, 1085, 1089, 1117, 1118, 1120, 1123, 1126, 1127, 1131, 1133, 1135, 1136, 1142, 1144

Beyaz Hüküm, 123, 124, 140

Bileşik Suç, 230, 679, 680

Bilinçli Taksir, 91, 245, 258, 259, 286, 287, 290, 291, 292, 295, 296, 298, 754, 852, 1055, 1057
 Bilinçsiz Taksir, 173, 290, 1056, 1057

C

Cebir, 58, 175, 183, 187, 227, 233, 303, 363, 376, 471, 476, 496, 497, 498, 501, 508, 539, 573, 588, 606, 629, 632, 635, 637, 676, 680, 798, 1055, 1069, 1070, 1146, 1147
 Ceza Hukuku Yaptırımı, 60, 62, 66, 67, 95, 119, 122, 221, 913, 970, 972, 999, 1039, 1041, 1163
 Ceza Yaptırımı, 85, 90, 97, 99, 104, 113, 115, 132, 180, 221, 273, 315, 473, 477, 588, 799, 810, 811, 1039, 1041, 1042
 Ceza Zamaşıması, 62, 96, 120, 154, 155, 864, 1101, 1102, 1103, 1104, 1187
 Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler, 244, 639, 753, 769, 1069, 1071, 1072
 Cezada Kanunilik İlkesi, 62, 85, 90, 120, 121, 122, 125, 129, 136, 140
 Cezaların İçtimai, 94, 812, 879
 Cezanın Amacı, 38, 810, 811, 813, 856
 Cezanın Belirlenmesi, 97, 98, 489, 538, 556, 587, 913, 914, 1051, 1052, 1055, 1057, 1058, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1075
 Cezanın Bireyselleştirilmesi, 97, 479, 811, 812, 845, 863, 865, 914, 915, 916, 987, 1051, 1060, 1061, 1062, 1072, 1088
 Cezanın İnfazı, 38, 58, 96, 97, 152, 156, 348, 483, 600, 769, 771, 794, 800, 812, 813, 855, 856, 870, 874, 875, 882, 884, 887, 969, 987, 989, 994, 995, 1025, 1026, 1027, 1030, 1031, 1033, 1035, 1050, 1084, 1101, 1102, 1103, 1107, 1157, 1220, 1224, 1225
 Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler, 243, 244, 753, 768
 Conditio Sine Qua Non, 63, 970

Ç

Çerçeve Kanun, 124

Çift Neticeli Sapma, 725
 Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbiri, 474, 477, 970, 973, 1020
 Çok Failli Suç, 600, 601
 Çok Hareketli Suç, 186, 401, 629

D

Daha Az Cezayı Gerektiren Hal, 1068
 Dava Zamaşıması, 193, 784, 907, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1102, 1105, 1106
 Davranış Normları, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 53, 54, 176, 177, 178, 239, 293, 306, 307, 308, 393, 398, 399, 461, 463, 467, 469, 472, 473, 499, 600, 719, 792
 Deneme Süresi, 151, 152, 861, 863, 870, 872, 873, 894, 895, 896, 898, 1025
 Denetim Süresi, 95, 151, 479, 813, 814, 856, 861, 870, 871, 872, 873, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 973, 1030, 1031, 1034, 1035, 1048, 1049, 1050, 1084, 1086
 Denetimli Serbestlik Tedbiri, 67, 97, 98, 151, 152, 153, 479, 870, 871, 872, 873, 882, 892, 893, 898, 899, 973, 1023, 1027, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1047, 1048, 1049, 1050
 Dikkat ve Özen Yükümlülüğü, 262, 263, 272, 273, 276, 278, 279, 286, 550, 565, 847, 848
 Dikkatsizlik, 170, 249, 250, 257, 275, 872
 Disiplin Hapsi, 907, 908, 909, 911, 1106
 Doğrudan Kast, 130, 246, 247, 250, 251, 254, 255, 256, 259, 314, 488, 516, 619, 1057
 Dokunulmazlık, 773
 Dolaylı Faillik, 603, 625, 632, 634, 635, 637, 638

E

Eksik Teşebbüs, 93, 574, 575, 581, 583, 584, 585, 586, 593
 Elverişsiz Teşebbüs, 543
 Emniyet Görevlisi, 514, 643
 Erime Sistemi, 721
 Erteleme, 95, 96, 150, 152, 844, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 894, 895

Ertelemenin Bölünmezliği, 859, 861
 Eşya Müsaderesi, 96, 971, 972, 973, 999,
 1000, 1003, 1012, 1013, 1042
 Etkin Pişmanlık, 80, 93, 94, 96, 98, 103, 244,
 591, 593, 594, 596, 597, 769, 798, 812,
 813, 855, 856, 863, 874, 987, 995, 1012,
 1048, 1071
 Evrensellik ve Koruma İlkesi, 1134

F

Faial Nedamet, 80, 230, 593, 594, 596, 653,
 771, 797
 Faal Pişmanlık, 80, 596, 800, 809
 Faaliyet İzninin İptali, 1041, 1042
 Fail, 69, 101, 116, 118, 140, 146, 151, 152,
 153, 156, 170, 171, 173, 181, 195, 196,
 197, 209, 214, 215, 221, 231, 232, 235,
 237, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 247,
 248, 250, 254, 256, 278, 283, 290, 291,
 293, 296, 298, 301, 302, 382, 401, 403,
 459, 460, 461, 469, 470, 487, 496, 497,
 512, 523, 536, 538, 541, 542, 543, 544,
 549, 551, 555, 563, 564, 574, 579, 580,
 581, 583, 584, 588, 590, 591, 592, 594,
 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 611,
 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637,
 638, 639, 641, 647, 649, 650, 655, 656,
 657, 671, 672, 673, 678, 681, 684, 694,
 708, 713, 723, 726, 741, 745, 769, 783,
 845, 849, 864, 915, 973, 1012, 1019, 1020,
 1066, 1067, 1068, 1073, 1114, 1118, 1124,
 1125, 1126, 1130, 1131, 1136, 1143, 1146,
 1155
 Faile Göre Şahsılık, 1122
 Fiil, 39, 59, 60, 65, 81, 85, 93, 100, 104, 116,
 118, 122, 125, 132, 136, 139, 140, 144,
 146, 152, 156, 158, 161, 163, 170, 175,
 176, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
 194, 209, 216, 217, 225, 226, 234, 235,
 237, 238, 242, 243, 244, 261, 293, 300,
 302, 304, 310, 311, 313, 336, 340, 361,
 362, 365, 368, 369, 375, 394, 459, 460,
 463, 465, 466, 467, 468, 471, 476, 481,
 482, 483, 484, 486, 487, 497, 498, 499,
 513, 522, 531, 532, 533, 541, 543, 545,

547, 549, 551, 553, 554, 555, 556, 563,
 564, 573, 578, 579, 580, 586, 594, 602,
 603, 607, 609, 610, 613, 615, 617, 619,
 620, 621, 625, 626, 627, 628, 629, 630,
 631, 632, 636, 637, 641, 646, 650, 653,
 670, 673, 675, 678, 679, 680, 683, 684,
 692, 702, 704, 707, 718, 726, 744, 745,
 746, 747, 748, 753, 768, 773, 780, 784,
 785, 792, 793, 795, 812, 864, 879, 907,
 918, 969, 1021, 1039, 1040, 1088, 1113,
 1114, 1117, 1119, 1120, 1191, 1193, 1195,
 1206, 1209, 1216, 1218, 1222

Fiil Ehliyeti, 183, 185, 216, 217, 467, 1039,
 1040

Fikri İctima, 725, 1069

G

Geceleri İnfaz, 844

Geçici Nedenler, 471, 476, 486, 798, 1069,
 1070

Genel Af, 863, 990, 991, 992, 995, 1109, 1111,
 1188

Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi, 108

Genel Kast, 303, 503, 547, 676

Gerçek İctima, 585, 675, 677, 679, 684, 694,
 695, 703, 710, 712, 713, 718, 719, 722,
 724, 746, 747, 873

Gerçek İhmalî Suç, 193, 588

Geriverme, 1136, 1156, 1157, 1158, 1159,
 1160, 1163, 1168, 1169, 1172, 1177, 1184,
 1186, 1187, 1188, 1189, 1191, 1195, 1199,
 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
 1207, 1208, 1211, 1214, 1215, 1218

Geriye Yürüme Yasası, 143

Gönüllü Vazgeçme, 80, 93, 590, 591, 593,
 594, 596, 599, 670, 671, 672, 673

Görev Suçları, 1122

Görevin İfası, 295, 317, 325, 326, 336, 534, 1122

Görevin Yerine Getirilmesi, 65, 318, 325, 340,
 345, 349, 389, 397, 507

Görünüşte İctima, 187, 718, 741

Görünüşte İhmalî Suç, 402, 403, 410, 588

Gözcülük, 604, 616, 617

Gün Para Cezası, 96, 829, 830, 833, 837, 838,
 845, 914, 916, 918, 1063

Güvenlik Tedbiri, 39, 67, 87, 88, 94, 96, 97, 99, 115, 122, 132, 144, 145, 165, 236, 460, 472, 474, 485, 582, 746, 791, 792, 795, 797, 798, 845, 853, 873, 896, 897, 920, 964, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 999, 1003, 1004, 1018, 1022, 1023, 1025, 1035, 1038, 1039, 1041, 1042, 1048, 1117, 1118, 1162, 1163, 1186, 1188

H

Hafifletici Sebepler, 230, 653

Hafta Sonları İnfaz, 904

Hak Yoksunluğu, 96, 485, 811, 871, 907, 911, 986, 987, 992, 993, 995, 996

Haksız Fiil, 37, 60, 254, 383, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 552, 577, 585, 632

Haksız Tahrik, 92, 230, 363, 367, 469, 472, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 552, 585, 653, 754, 1070, 1091

Haksızlık, 30, 36, 37, 38, 39, 53, 55, 66, 94, 106, 113, 117, 118, 121, 137, 155, 161, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 186, 187, 216, 223, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 256, 259, 262, 263, 272, 273, 293, 306, 310, 311, 312, 313, 341, 346, 364, 365, 398, 399, 401, 411, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 474, 497, 498, 499, 522, 523, 529, 531, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 553, 554, 555, 556, 557, 563, 564, 565, 585, 600, 602, 603, 606, 625, 632, 640, 647, 650, 652, 656, 672, 753, 772, 773, 774, 781, 791, 792, 794, 795, 796, 798, 812, 855, 969, 991, 1001, 1023, 1040, 1051, 1052, 1055, 1057, 1060, 1070, 1088, 1089, 1195

Haksızlık Bilinci, 463, 554

Haksızlık İçeriği, 118, 177, 178, 310, 781, 798, 1051, 1052, 1057, 1060

Haksızlık Unsuru, 164, 167, 171, 173, 174, 175, 238, 262, 470, 471

Haksızlık Yanılgısı, 466, 470, 544, 545, 546, 554, 555, 556

Hapis Cezası, 66, 67, 94, 95, 96, 98, 101, 130, 144, 149, 150, 151, 152, 230, 325, 332, 374,

476, 477, 478, 479, 484, 485, 633, 638, 647, 682, 744, 807, 810, 811, 812, 813, 814, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 838, 844, 845, 849, 852, 853, 855, 856, 858, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 879, 880, 882, 884, 886, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 905, 907, 908, 914, 915, 916, 917, 972, 973, 974, 986, 987, 989, 990, 991, 995, 1023, 1024, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034, 1035, 1036, 1038, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1068, 1073, 1075, 1083, 1084, 1085, 1086, 1090, 1091, 1103, 1106, 1109, 1110, 1120, 1124, 1125, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1183, 1184

Hapis Cezasının Ertelenmesi, 144, 149, 152, 479, 844, 853, 855, 858, 863, 866, 869, 870, 871, 973, 1049

Hata, 171, 242, 313, 400, 461, 464, 472, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 547, 548, 549, 551, 553, 556, 562, 625, 722, 725, 1055, 1070

Hazırlık Hareketleri, 563, 568, 569, 573, 574, 577, 617, 618, 646

Hedefte Sapma, 541, 626, 641, 722, 723, 724

Hukuka Aykırılık, 60, 121, 162, 167, 169, 171, 175, 176, 178, 181, 236, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 324, 325, 362, 369, 384, 397, 411, 460, 465, 500, 508, 544, 545, 549, 969

Hukuka Özel Aykırılık, 315

Hukuka Uygunluk Nedenleri, 66, 92, 242, 314, 316, 317, 318, 397, 501, 513, 515, 516, 522, 539, 549

Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması, 314, 513, 515, 522

Hukuki Değer, 53, 78, 82, 86, 89, 111, 121, 169, 176, 177, 178, 179, 180, 222, 223, 224, 227, 262, 263, 278, 365, 367, 374, 376, 385, 398, 399, 463, 470, 471, 497, 498, 542, 564, 582, 600, 613, 650, 719, 794, 1040, 1125

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, 478, 479, 480, 814, 815, 838, 897, 1048

I

İcra Hareketleri, 93, 199, 228, 401, 487, 563, 568, 569, 573, 574, 576, 577, 579, 582,

583, 584, 585, 587, 590, 591, 592, 593,
594, 606, 629, 648, 649, 655, 670, 671,
672, 745, 1002, 1113, 1114, 1115, 1206
İcraî Hareket, 166, 564, 574, 576, 577, 584,
606, 607, 610, 611, 612, 613, 614, 617,
630, 632
İcraî Suç, 631, 642
İçtima, 80, 90, 101, 109, 187, 239, 541, 679,
680, 691, 702, 703, 704, 705, 707, 708,
711, 712, 713, 718, 719, 720, 721, 722,
724, 726, 731, 741, 746, 747, 859, 860,
1069
İdam Cezası, 69, 197, 807
İdari Para Cezası, 66, 117, 119, 221, 222, 305,
539, 673, 674, 746, 747, 812, 913, 914,
918, 1019, 1036, 1037, 1038, 1104, 1105
İdari Tedbir, 1018, 1019, 1020, 1039, 1160,
1163
İdari Yaptırım, 59, 66, 91, 95, 102, 106, 113,
117, 119, 121, 140, 159, 220, 221, 273,
746, 748, 913, 1019, 1037, 1041, 1106,
1153
İhmali Suç, 588
İhtiyariyle Vazgeçme, 591, 593
İlgilinin Rızası, 318, 347, 369, 397
İlliyyet Bağ, 104, 193, 194, 195, 199, 200, 202,
209, 210, 225, 274, 276, 282, 410, 607,
610, 623
İn Dubio Pro Reo, 612, 626, 627
İrade Hürriyeti, 25, 165, 179, 467, 468, 498,
508, 509
İrade Yeteneği, 293, 462, 466, 469, 471, 472,
474, 475, 476, 482, 483, 484, 486, 487,
488, 496, 498, 1055, 1069, 1070
İsnat Kabiliyeti, 795
İsnat Yeteneği, 162, 490, 635
İstem Belgesi, 1211
İşlenemez Suç, 543, 579, 580, 581, 582
İter Criminis, 243, 563, 753
İtiyadı Suçlu, 883

K

Kabahat, 59, 66, 91, 94, 95, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 140, 159, 177, 178, 180,

221, 260, 304, 305, 539, 673, 746, 810,
811, 858, 911, 913, 914, 1036, 1037, 1038
Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, 478,
479, 480, 814, 815, 838, 897
Kamu Görevlisi, 90, 101, 187, 188, 215, 229,
231, 240, 242, 303, 304, 325, 347, 348,
400, 514, 543, 544, 630, 655, 656, 657,
676, 677, 712, 713, 742, 745, 910, 1066
Kanunilik İlkesi, 119, 122, 124, 140
Kanunun Hükmünü İcra, 338, 534, 548, 549
Kanunun Hükmünün Yerine Getirilmesi, 325
Karşılıklılık, 1158, 1210
Kast, 91, 101, 116, 162, 165, 167, 170, 171,
174, 186, 235, 237, 238, 239, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 254, 257, 258,
259, 290, 292, 295, 301, 303, 304, 368,
461, 465, 467, 487, 503, 513, 516, 540,
541, 545, 554, 555, 566, 593, 619, 646,
676, 706, 726, 779, 798, 1052, 1055, 1057,
1199
Kastın Bilme Unsuru, 175, 244
Kazanç Müsaderesi, 96, 104, 829, 830, 908,
912, 915, 916, 917, 971, 973, 999, 1002,
1003, 1004, 1005, 1012, 1020, 1042, 1064,
1108
Kesintisiz Suç, 785, 1091
Kısa Süreli Hapis Cezası, 94, 98, 111, 477, 479,
811, 844, 845, 848, 849, 853, 855, 862,
896, 897, 971, 973, 1025, 1049, 1084,
1086
Kısmi Akıl Hastalığı, 485
Kıyas, 138
Kıyas, 85, 90, 120, 121, 134, 136, 137, 138,
139, 593
Kıyas Yasağı, 85, 90, 121, 134, 136, 137, 138
Kolluk Görevlisi, 337
Koruma Tedbiri, 325, 911, 1083, 1216
Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler, 474, 970,
1020, 1021
Koşullu Salıverilme, 66, 144, 148, 149, 153,
812, 844, 874, 875, 877, 878, 879, 882,
883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890,
891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899,
963, 1023, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034,
1035, 1036, 1038, 1049, 1050, 1075, 1086

Kriminoloji, 60, 374, 1148, 1156

Kusur, 29, 30, 38, 39, 85, 92, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 172, 173, 175, 176, 177, 184, 185, 186, 197, 216, 235, 236, 237, 238, 242, 250, 259, 261, 263, 276, 278, 282, 283, 293, 294, 314, 364, 370, 411, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 469, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 499, 500, 523, 528, 529, 545, 546, 547, 553, 554, 556, 632, 637, 673, 780, 792, 793, 794, 795, 796, 966, 969, 1001, 1021, 1040, 1089

Kusur Ehliyeti, 29, 185, 216, 236, 460, 467, 478, 480, 796, 1040

Kusur Yeteneği, 93, 170, 173, 185, 236, 364, 460, 463, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 523, 528, 632, 637, 673, 780, 795, 1021

Kusurluluk, 37, 38, 39, 91, 162, 164, 167, 171, 173, 181, 183, 185, 186, 226, 234, 236, 237, 238, 240, 245, 246, 257, 259, 278, 279, 311, 341, 459, 460, 461, 462, 464, 470, 472, 486, 490, 500, 508, 539, 551, 553, 792, 793, 796, 968, 970, 1023, 1051, 1055, 1058

Kusursuz Ceza Olmaz, 39, 92, 301, 487, 794, 795, 969, 1039, 1181, 1230, 1246

M

Maddi Unsur, 161, 168, 169, 171, 181, 182, 187, 193, 194, 222, 223, 226, 228, 236, 237, 239, 242, 244, 246, 247, 249, 261, 290, 292, 295, 315, 369, 398, 411, 460, 467, 540, 541, 563, 582, 583, 588, 607, 635

Mağdur, 37, 93, 101, 197, 210, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 232, 283, 286, 287, 288, 346, 384, 498, 533, 534, 584, 585, 594, 607, 614, 653, 655, 677, 690, 691, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 719, 754, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 814, 830, 917, 1106, 1107, 1125, 1131

Mağdura Göre Şahsılık, 1130

Mağdurun Rızası, 376

Mahsup, 861, 895, 1081, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1130, 1133, 1136, 1144

Mahsus Suç, 651

Maksat, 82, 175, 575

Mali Suç, 1203, 1204

Manevi Unsur, 91, 116, 173, 181, 182, 186, 234, 235, 238, 303, 304, 369, 459, 465, 545, 546, 620, 638, 676

Mazeret Sebebi, 361, 498, 499, 500, 501, 508, 511, 523, 524, 532, 533, 539, 637

Meslek ve Sanatın Tatili İcrası, 115

Meşru Müdafaa, 193, 319, 331, 333, 341, 342, 361, 516, 522, 523, 532, 544, 550, 1129

Meşru Savunma, 317, 318, 327, 328, 331, 335, 340, 341, 344, 345, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 397, 476, 515, 516, 522, 523, 548, 798

Muafiyet, 773, 774

Muaheze Yargısı, 235, 459, 462, 466, 469, 792, 796

Muhtemel Kast, 210, 255, 258, 295, 301, 516, 568, 723, 733

Mutlak Dokunulmazlık, 754

Mutlak Kuvvet, 245, 496

Mücbir Sebep, 390, 502, 523

Müebbet Ağır Hapis Cezası, 654, 809, 885, 1025

Müebbet Hapis Cezası, 476, 536, 638, 647, 811, 879, 880, 882, 1028, 1073, 1075, 1090

Mükerrer Değerlendirme Yasağı, 587, 1057, 1058, 1060, 1068, 1072

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, 1017, 1018, 1019, 1020, 1105, 1106

Müstakil Fail, 603, 606, 614, 620, 621, 622, 623, 629, 630, 656

Müşterek Faillik, 600, 603, 606, 607, 611, 612, 615, 617, 619, 621, 622, 625, 628, 629, 631, 648, 649, 654, 656, 657

Mütemadi Suç, 186, 192, 193, 587, 588

N

Nedensellik Bağı, 410

Netice, 34, 85, 92, 101, 105, 161, 163, 166, 167, 172, 173, 186, 193, 194, 195, 196, 209, 236, 238, 239, 249, 250, 261, 273, 274, 276, 282, 285, 286, 287, 298, 301, 302, 308, 313, 339, 350, 390, 401, 410, 411, 519, 541, 542, 563, 566, 575, 584, 585, 594, 610, 621, 623, 631, 632, 641, 702, 703, 707, 719, 725, 733, 794, 1113

Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç, 92, 101, 298, 302, 339, 623, 641, 733

Neticesi Harekete Bitişik Suç, 193, 194

Nitelikli Hal, 111, 640, 655, 677, 682, 684, 692, 720, 830, 918, 1065, 1066, 1091

Nitelikli Unsur, 93, 188, 230, 231, 232, 233, 242, 304, 540, 541, 543, 584, 585, 615, 628, 648, 655, 675, 677, 682, 684, 712, 745, 1065, 1066, 1068

Non Bis İn İdem, 39, 90, 746, 837, 973, 1086, 1116, 1117, 1118, 1120, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1144, 1151, 1201, 1208, 1209

Nulla Poena Sine Culpa, 39, 301, 792, 795, 969

Nulla Poena Sine Lege, 120

O

Objektif Cezalandırılabilme Şartı, 226, 243, 273, 774, 777, 797

Objektif Özen Yükümlülüğü, 167, 173, 186, 238, 262, 274, 278, 282, 470, 471, 519, 632, 1000

Objektif Sorumluluk, 81, 92, 116, 118, 260, 305, 811

Olası Kast, 91, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 259, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 301, 488, 619, 1055, 1057

Oturduğu Yerde İnfaz, 905

Ö

Ölüm Cezası, 63, 73, 74, 806, 807, 808, 809, 810, 1189, 1190

Önödeme, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 907, 1029

Örgüt, 104, 121, 192, 225, 303, 344, 345, 507, 568, 597, 601, 602, 618, 619, 676, 677, 770, 877, 882, 883, 1033, 1034, 1035, 1048, 1050, 1092, 1102, 1196

Örgüt Mensubu Suçlu, 97, 877, 882, 883, 1033, 1034, 1050

Özel Af, 864, 990, 991, 992, 1109, 1110, 1111, 1127, 1188

Özel İnfaz Şekilleri, 844, 899, 904

Özel Kast, 303, 503, 676

Özellik Kuralı, 1222, 1223, 1224

Özgü Suç, 215, 231, 629, 639, 651, 673

R

Refleks Hareketler, 184

Rıza, 86, 322, 371, 373, 374, 375, 377, 383, 384, 385, 386, 389, 392, 550, 602, 912, 1115, 1224

S

Sağır ve Dilsizlik, 471, 476, 485, 486, 798, 1069

Saik, 233, 303, 304, 533, 676, 1058, 1192, 1193, 1196

Seçenek Yaptırımlar, 94, 111, 477, 479, 811, 845, 847, 849, 907, 1049

Seçimlik Ceza, 827, 831, 833, 859, 896, 897, 1062, 1091

Seçimlik Hareketli Suç, 186, 188, 189

Serbest Hareketli Suç, 186, 187, 188, 401

Sığınma, 1156, 1158, 1159, 1191

Sınır Dışı Etme, 1038, 1039, 1160, 1161, 1162, 1163

Silah, 188, 226, 230, 250, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 363, 508, 510, 514, 516, 517, 518, 547, 563, 570, 579, 581, 591, 615, 624, 655, 721, 724, 726, 1002, 1003

Silah Kullanma Yetkisi, 40, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 339, 340, 341, 342, 344, 516, 517, 518, 547, 801

Siyasi Suç, 1148, 1158, 1168, 1191, 1192, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199, 1200, 1202, 1214, 1215

Somut Tehlike Suçu, 104, 224, 225

Sorumsuzluk, 473, 508, 1140

Soyut Tehlike Suçu, 224, 225

Suç, 25, 53, 80, 85, 87, 94, 97, 98, 108, 109, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 161, 163, 165, 170, 175, 176, 195, 214, 243, 244, 286, 491, 548, 566, 584, 587, 619, 684, 691, 692, 702, 703, 704, 705, 706, 712, 718, 719, 723, 724, 746, 810, 828, 833, 871, 872, 893, 1065, 1099, 1123, 1206, 1208

Suç Örgütü, 883, 1034

Suç Yolu, 97, 563, 564, 591

Suç İştirak, 83, 93, 118, 121, 162, 166, 169, 170, 176, 177, 178, 193, 195, 196, 200, 215, 240, 242, 279, 285, 398, 404, 464, 543, 553, 573, 600, 602, 603, 604, 607, 618, 626, 628, 630, 632, 635, 636, 640, 648, 649, 651, 652, 653, 656, 672, 673, 674, 1115

Suç Sürüklenen Çocuk, 67, 472

Suç Teşebbüs, 93, 118, 177, 178, 193, 549, 563, 564, 566, 568, 570, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 599, 639, 670, 1068, 1186

Suçların İçtimai, 93, 109, 111, 187, 541, 564, 631, 675, 718, 720, 742, 744, 747, 785, 812, 879, 1069

Suçluların Geriverilmesi, 1157

Suçluların İadesi, 58, 69, 71, 72, 1114, 1156, 1157, 1160, 1161, 1168, 1169, 1170, 1171, 1174, 1185, 1186, 1189, 1190, 1198, 1204

Suçta Kanunilik İlkesi, 106, 121, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 140

Suçtan Zarar Gören, 227, 229, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 814, 869, 1106, 1108, 1122, 1131, 1134

Suçlu Meslek Edinen Kişi, 97, 882, 883, 1033, 1034, 1050

Suçun Konusu, 130, 179, 189, 190, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 239, 558, 564, 580, 581, 582, 624, 627, 641, 708, 710, 712, 723, 724, 970, 971, 973, 1002, 1004, 1052, 1068, 1069, 1072

Suçun Konusunda Yanılma, 723

Suçun Tamamlanması, 189, 192, 194, 209, 566, 588, 590, 591, 593, 646

Ş

Şahista Hata, 541

Şahista Yanılma, 724

Şahsi Cezasızlık Sebebi, 243, 244, 287, 523, 635, 753, 754, 772, 773, 774, 795, 797, 798

Şartla Salıverilme, 149, 153, 874, 886, 887, 889, 891, 894, 895, 896, 907, 1035

Şartla Salıverme, 875, 887, 891, 894, 895, 896, 898

Şartla Tahliye, 887, 894, 895, 896

Şikâyet, 255, 580, 592, 683, 684, 707, 772, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 1106, 1107, 1124

Şikâyetin Geri Alınması, 1106

Şikâyetten Vazgeçme, 780, 786, 1106, 1107, 1111

T

Takdiri İndirim Nedenleri, 479, 868, 1060, 1072, 1073

Taksir, 92, 162, 165, 167, 171, 197, 237, 257, 258, 259, 261, 262, 279, 281, 285, 290, 291, 295, 299, 301, 304, 461, 516, 541, 555, 623, 631, 1055, 1057

Taksirli Suç, 163, 167, 170, 171, 172, 173, 195, 262, 273, 278, 279, 285, 286, 287, 295, 470, 471, 515, 623, 631, 632, 754, 852, 990, 1000, 1027, 1185

Talepname, 1211, 1212, 1213, 1215, 1223

Tam Teşebbüs, 93, 568, 583, 584, 585, 586, 591, 592, 593, 621, 724

Tasarlama, 482, 537, 653

Tazyik Hapsi, 862, 909, 911, 1106

Tehdit, 175, 184, 222, 227, 233, 246, 303, 376, 391, 392, 471, 476, 496, 497, 498, 501, 508, 539, 573, 588, 632, 635, 637, 648, 676, 678, 680, 707, 711, 721, 798, 1055, 1069, 1070, 1146, 1195, 1196

Tehlike Suçu, 101, 223, 224, 226

Tekerrür, 97, 116, 118, 148, 152, 478, 480, 811, 834, 853, 872, 882, 887, 987, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038

Terör Örgütü, 344, 345, 548, 1196

Terör Suçu, 1196

Teşebbüs, 90, 93, 109, 116, 118, 178, 189, 192, 195, 199, 239, 247, 251, 293, 296, 327, 328, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 366, 533, 534, 563, 564, 565, 566, 573, 574, 575, 577, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 592, 593, 596, 599, 613, 614, 615, 637, 639, 640, 646, 652, 671, 672, 723, 724, 731, 733, 811, 834, 859, 894, 1001, 1002, 1012, 1068, 1091, 1147, 1186, 1193, 1198, 1202, 1205

Teşebbüs Suçu, 563, 564, 573, 575, 579, 580, 585, 587, 614, 731, 894

Tıbbî Müdahale, 198, 314, 374, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 402

Tutuklama, 63, 105, 327, 332, 342, 911, 1083, 1094, 1212, 1215, 1216, 1217

Tüzel Kişi, 97, 112, 124, 183, 216, 217, 220, 221, 222, 228, 693, 782, 869, 974, 1000, 1006, 1039, 1040, 1041, 1042, 1131, 1133, 1154, 1155, 1207

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri, 1042

U

Unsur Yanılgısı, 171, 242, 370, 541, 543, 545, 546, 547, 555

Uyuşturucu Madde, 67, 68, 71, 72, 188, 471, 486, 488, 489, 490, 491, 1065, 1069, 1070, 1119, 1120, 1137, 1147, 1156, 1201, 1204, 1205

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde, 58, 97, 98, 188, 192, 488, 587, 597, 602, 721, 770, 971, 1002, 1004, 1027, 1065, 1069, 1120, 1134, 1143, 1204

Uzlaşma, 92, 683, 814, 831, 838

Uzun Süreli Hapis Cezası, 1029

V

Vatandaş, 89, 639, 1122, 1123, 1124, 1134, 1136, 1141, 1147, 1160, 1177, 1201, 1205, 1209, 1210, 1211

Vis Absoluta, 183, 245, 496

Vis Compulsiva, 183, 496

Y

Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması, 1154, 1155

Yakalama, 63, 327, 329, 330, 332, 334, 342, 515, 516, 528, 534, 1098, 1212, 1216

Yanılma, 313, 461, 465, 528, 546, 641, 723, 724

Yardım Etme, 325, 330, 399, 603, 604, 622, 625, 628, 636, 641, 646, 647, 649, 672

Yardımcı Norm, 564, 718, 744

Yaş Küçüklüğü, 29, 177, 461, 471, 472, 476, 486, 539, 637, 780, 798, 834, 1003, 1005, 1069, 1070, 1091

Yer Bakımından Uygulama, 90, 102, 160, 1113, 1143, 1153

Yetkili Mercinin Emrini İfa, 341, 506, 507

Yorum, 90, 134, 135, 136, 138, 139, 163, 653, 706, 741, 772, 1085, 1197

Yükümlülük Suçları, 215, 629

Z

Zaman Bakımından Uygulama, 65, 66, 119, 140, 144, 145, 146, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 159, 779, 780, 1183

Zamanaşımı, 119, 153, 154, 780, 785, 786, 908, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1095, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1187

Zamanaşımının Kesilmesi, 1095, 1098

Zarar Suçu, 223, 224, 226

Zaruret Hali, 166, 170, 236, 460, 499, 502, 522

Zor Kullanma Yetkisi, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 514, 515

Zorla Getirme, 326, 327

Zorlayıcı Kuvvet, 183, 496, 497

Zorunlu İştirak, 600

Zorunluluk Hali, 180, 293, 294, 317, 375, 376, 385, 393, 395, 472, 476, 498, 501, 502, 508, 513, 522, 539, 551, 798, 1055, 1069, 1070, 1071